

CNUDMI Anuario

Volumen XLIV: 2013



**COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL**

ANUARIO

Volumen XLIV: 2013



**NACIONES UNIDAS
Nueva York, 2016**

NOTA

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

La numeración de las notas de pie de página se ajusta a la empleada en los documentos originales en los que se basa el presente *Anuario*. Las notas de pie de página añadidas posteriormente se indican mediante letras minúsculas.

Las modificaciones y adiciones a los textos publicados en anteriores proyectos de convenciones, leyes modelo y otros textos jurídicos figuran en bastardilla, salvo en el caso de los encabezamientos de artículos, que figuran en bastardilla por razones de presentación.

A/CN.9/SER.A/2013

ISSN 0251-4273

© Naciones Unidas, noviembre de 2016. Reservados todos los derechos a nivel mundial.

Producción de la publicación: Sección de Servicios en Inglés, Publicaciones y Biblioteca, Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

ÍNDICE

	<i>Página</i>
INTRODUCCIÓN	viii
Primera parte. Informe de la Comisión sobre su período de sesiones anual y observaciones y decisiones relativas al informe	
EL 46° PERÍODO DE SESIONES (2013)	3
A. Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, sobre su 46° período de sesiones (Viena, 8 a 26 de julio de 2013) (A/68/17)	3
B. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): pasajes del informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 60° período de sesiones (TD/B/60/11)	105
C. Asamblea General: Informe de la Sexta Comisión relativo al informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 46° período de sesiones (A/68/462)	106
D. Resoluciones 68/106, 68/107, 68/108, 68/109 y 68/116 de la Asamblea General	121
Segunda parte. Estudios e informes sobre cuestiones concretas	
I. ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN	139
A. Informe del Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación sobre la labor realizada en su 57° período de sesiones (Viena, 1 a 5 de octubre de 2012) (A/CN.9/760)	139
B. Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales: preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 57° período de sesiones (A/CN.9/WG.II/WP.172)	165
C. Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales: preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entablados entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado — Observaciones presentadas por instituciones arbitrales acerca de las relaciones entre el proyecto de reglamento sobre la transparencia y sus respectivas reglas institucionales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 57° período de sesiones (A/CN.9/WG.II/WP.173) ...	175
D. Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales: preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entablados entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado — Propuesta presentada por los Gobiernos de la Argentina, Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, México, Noruega y Sudáfrica, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 57° período de sesiones (A/CN.9/WG.II/WP.174)	190
E. Informe del Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación sobre la labor realizada en su 58° período de sesiones (Nueva York, 4 a 8 de febrero de 2013) (A/CN.9/765)	194

F.	Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales: preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 58º período de sesiones (A/CN.9/WG.II/WP.176 y Add.1)	217
G.	Nota de la Secretaría relativa al establecimiento de un archivo de la información publicada (“registro”): solución de controversias comerciales: preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 58º período de sesiones (A/CN.9/WG.II/WP.177)	248
H.	Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales: Guía de la CNUDMI relativa a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958): Extracto de la guía sobre el artículo VII (A/CN.9/786)	255
II.	COMERCIO ELECTRÓNICO	277
A.	Informe del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico sobre la labor realizada en su 46º período de sesiones (Viena, 29 de octubre a 2 de noviembre de 2012) (A/CN.9/761).	277
B.	Nota de la Secretaría sobre cuestiones jurídicas relativas a la utilización de documentos transmisibles electrónicos, presentada al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 46º período de sesiones (A/CN.9/WG.IV/WP.118 y Add.1)	294
C.	Nota de la Secretaría sobre cuestiones jurídicas relativas a la utilización de documentos transmisibles electrónicos — Propuesta de los Gobiernos de Colombia, España y los Estados Unidos, presentada al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 46º período de sesiones (A/CN.9/WG.IV/WP.119).	328
D.	Nota de la Secretaría — Panorama general de la gestión de la identidad — Documento de antecedentes presentado por el <i>Identity Management Legal Task Force</i> de la <i>American Bar Association</i> , presentada al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 46º período de sesiones (A/CN.9/WG.IV/WP.120)	343
E.	Informe del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico sobre la labor realizada en su 47º período de sesiones (Nueva York, 13 a 17 de mayo de 2013) (A/CN.9/768).	362
F.	Nota de la Secretaría sobre proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos, presentada al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 47º período de sesiones (A/CN.9/WG.IV/WP.122)	382
III.	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LÍNEA	405
A.	Informe del Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea sobre la labor realizada en su 26º período de sesiones (Viena, 5 a 9 de noviembre de 2012) (A/CN.9/762).	405
B.	Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 26º período de sesiones (A/CN.9/WG.III/WP.117 and Add.1)	422
C.	Informe del Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea sobre la labor de su 27º período de sesiones (Nueva York, 20 a 24 de mayo de 2013) (A/CN.9/769)	453

D.	Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 27° período de sesiones (A/CN.9/WG.III/WP.119 and Add.1)	473
E.	Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: plazos, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 27° período de sesiones (A/CN.9/WG.III/WP.120)	511
F.	Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento — Propuesta de la delegación de observadores de la Unión Europea, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 27° período de sesiones (A/CN.9/WG.III/WP.121)	516
IV.	RÉGIMEN DE LA INSOLVENCIA	525
A.	Informe del Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia sobre la labor realizada en su 42° período de sesiones (Viena, 26 a 30 de noviembre de 2012) (A/CN.9/763)	525
B.	Nota de la Secretaría sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos enunciados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses (COMI), presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la insolvencia en su 42° período de sesiones (A/CN.9/WG.V/WP.107)	546
C.	Nota de la Secretaría sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 42° período de sesiones (A/CN.9/WG.V/WP.108)	566
D.	Nota de la Secretaría sobre la insolvencia de las instituciones financieras grandes y complejas, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 42° período de sesiones (A/CN.9/WG.V/WP.109)	586
E.	Nota de la Secretaría sobre el régimen de la insolvencia: asistencia y cooperación técnicas, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 42° período de sesiones (A/CN.9/WG.V/WP.110)	609
F.	Informe del Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia sobre la labor realizada en su 43° período de sesiones (Nueva York, 15 a 19 de abril de 2013) (A/CN.9/766)	611
G.	Nota de la Secretaría sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos enunciados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43° período de sesiones (A/CN.9/WG.V/WP.112)	630
H.	Nota de la Secretaría sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43° período de sesiones (A/CN.9/WG.V/WP.113)	663

I.	Nota de la Secretaría sobre el centro de los principales intereses en el contexto de los grupos de empresas, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43° período de sesiones (A/CN.9/WG.V/WP.114)	690
J.	Nota de la Secretaría sobre los grupos de empresas — Obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43° período de sesiones (A/CN.9/WG.V/WP.115)	696
K.	Nota de la Secretaría sobre la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial (A/CN.9/778).....	708
V.	GARANTÍAS REALES	753
A.	Informe del Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales sobre la labor realizada en su 22° período de sesiones (Viena, 10 a 14 de diciembre de 2012) (A/CN.9/764)	753
B.	Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 22° período de sesiones (A/CN.9/WG.VI/WP.52 y Add.1 a Add.6).....	771
C.	Informe del Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales sobre la labor realizada en su 23° período de sesiones (Nueva York, 8 a 12 de abril de 2013) (A/CN.9/767).....	889
D.	Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23° período de sesiones (A/CN.9/WG.VI/WP.54 y Add.1 a Add.6).....	907
E.	Nota de la Secretaría sobre el proyecto de ley modelo sobre las operaciones garantizadas, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23° período de sesiones (A/CN.9/WG.VI/WP.55 y Add.1 a Add.4).....	1030
VI.	CONTRATACIÓN PÚBLICA	1099
A.	Nota de la Secretaría sobre directrices para la promulgación de un reglamento de la contratación pública de conformidad con el artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública (A/CN.9/770)	1099
B.	Nota de la Secretaría sobre el glosario de términos relacionados con la contratación pública utilizados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública (A/CN.9/771).....	1174
VII.	LABOR FUTURA.....	1201
A.	Labor prevista y posible labor futura (A/CN.9/774)	1201
B.	Posible labor futura en la esfera de la colaboración entre el sector público y el privado — Informe del coloquio de la CNUDMI sobre la colaboración entre el sector público y el privado (Viena, 2 y 3 de mayo de 2013) (A/CN.9/779)	1218
C.	Microfinanciación: creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (A/CN.9/780).....	1240
D.	Solución de controversias comerciales: posible labor futura en materia de solución de controversias comerciales (A/CN.9/785)	1263
E.	Fraude comercial (A/CN.9/788)	1271
F.	Propuesta del Gobierno de los Estados Unidos relativa a la labor futura de la CNUDMI: Tema 16 del programa provisional (A/CN.9/789).....	1277
G.	Propuesta del Gobierno de Colombia (A/CN.9/790)	1288

VIII.	JURISPRUDENCIA RELATIVA A LOS TEXTOS DE LA CNUDMI (CLOUT)	1303
IX.	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REFORMA JURÍDICA	1305
	Nota de la Secretaría sobre cooperación y asistencia técnicas (A/CN.9/775)	1305
X.	SITUACIÓN ACTUAL Y PROMOCIÓN DE LOS TEXTOS JURÍDICOS DE LA CNUDMI	1329
	Nota de la Secretaría sobre la situación actual de las convenciones y leyes modelo (A/CN.9/773)	1329
XI.	COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN	1331
	Nota de la Secretaría sobre las actividades de coordinación (A/CN.9/776)	1331

Tercera parte. Anexos

I.	ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL	1341
II.	BIBLIOGRAFÍA DE OBRAS RECIENTEMENTE PUBLICADAS RELATIVAS A LA LABOR DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (A/CN.9/772)	1461
III.	LISTA DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL	1505
IV.	LISTA DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL REPRODUCIDOS EN VOLÚMENES ANTERIORES DEL <i>ANUARIO</i>	1517

INTRODUCCIÓN

El presente es el 44º volumen de la serie de *Anuarios* de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)¹.

Este volumen consta de tres partes. La primera parte contiene el informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 46º período de sesiones, celebrado en Viena, del 8 al 26 de julio de 2013, y las decisiones adoptadas al respecto por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Asamblea General.

La segunda parte reproduce la mayoría de los documentos examinados por la Comisión en su 46º período de sesiones. Entre estos documentos figuran los informes de los Grupos de Trabajo de la Comisión, así como los estudios, informes y notas de la Secretaría. En esta segunda parte figuran asimismo algunos de los documentos de trabajo que se prepararon para los Grupos de Trabajo.

La tercera parte contiene actas resumidas, la bibliografía de obras recientemente publicadas relativas a la labor de la Comisión, una lista de documentos anteriores al 46º período de sesiones y una lista de documentos relativos a la labor de la Comisión que fueron reproducidos en los volúmenes anteriores del *Anuario*.

Secretaría de la CNUDMI
Centro Internacional de Viena
Apartado Postal 500, A-1400 Viena (Austria)
Teléfono: (+43-1) 26060-4060 Telefax: (+43-1) 26060-5813
Correo electrónico: uncitral@uncitral.org Internet: www.uncitral.org

¹ Los volúmenes del *Anuario de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional* (denominado en adelante *Anuario* [año]) que se han publicado hasta la fecha son los siguientes:

<i>Volumen</i>	<i>Años</i>	<i>Publicación de las Naciones Unidas</i>
		<i>Núm. de venta o signatura</i>
I	1968-1970	E.71.V.1
II	1971	E.72.V.4
III	1972	E.73.V.6
III Suplemento	1972	E.73.V.9
IV	1973	E.74.V.3
V	1974	E.75.V.2
VI	1975	E.76.V.5
VII	1976	E.77.V.1
VIII	1977	E.78.V.7
IX	1978	E.80.V.8
X	1979	E.81.V.2
XI	1980	E.81.V.8
XII	1981	E.82.V.6
XIII	1982	E.84.V.5

<i>Volumen</i>	<i>Años</i>	<i>Publicación de las Naciones Unidas</i>	
		<i>Núm. de venta o signatura</i>	
XIV	1983	E.85.V.3	
XV	1984	E.86.V.2	
XVI	1985	E.87.V.4	
XVII	1986	E.88.V.4	
XVIII	1987	E.89.V.4	
XIX	1988	E.89.V.8	
XX	1989	E.90.V.9	
XXI	1990	E.91.V.6	
XXII	1991	E.93.V.2	
XXIII	1992	E.94.V.7	
XXIV	1993	E.94.V.16	
XXV	1994	E.95.V.20	
XXVI	1995	E.96.V.8	
XXVII	1996	E.98.V.7	
XXVIII	1997	E.99.V.6	
XXIX	1998	E.99.V.12	
XXX	1999	E.00.V.9	
XXXI	2000	E.02.V.3	
XXXII	2001	E.04.V.4	
XXXIII	2002	E.05.V.13	
XXXIV	2003	E.06.V.14	
XXXV	2004	E.08.V.8	
XXXVI	2005	E.10.V.4	
XXXVII	2006	A/CN.9/SER.A/2006	
XXXVIII	2007	A/CN.9/SER.A/2007	
XXXIX	2008	A/CN.9/SER.A/2008	
XL	2009	A/CN.9/SER.A/2009	
XLI	2010	A/CN.9/SER.A/2010	
XLII	2011	A/CN.9/SER.A/2011	
XLIII	2012	A/CN.9/SER.A/2012	

Primera parte

INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE
SU PERÍODO DE SESIONES ANUAL Y
OBSERVACIONES Y DECISIONES
RELATIVAS AL INFORME

El 46° PERÍODO DE SESIONES (2013)

A. Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre su 46° período de sesiones (Viena, 8 a 26 de julio de 2013) (A/68/17)

[Original: inglés]

Índice

Capítulo

I.	Introducción	
II.	Organización del período de sesiones	
A.	Apertura del período de sesiones	
B.	Composición y asistencia	
C.	Elección de la Mesa	
D.	Programa	
E.	Aprobación del informe	
III.	Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación	
A.	Finalización y aprobación de una versión revisada del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado	
B.	Examen de instrumentos relativos a la aplicabilidad del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado a la solución de controversias surgidas en el marco de tratados de inversión ya existentes	
C.	Decisión por la que se aprueba el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013)	
D.	Labor futura	
E.	Preparación de una guía sobre la Convención de Nueva York de 1958	
F.	Concursos de arbitraje comercial internacional simulado	
IV.	Examen de cuestiones relacionadas con las garantías reales	
A.	Finalización y aprobación de la Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales	
B.	Informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo VI y labor futura	
V.	Examen de cuestiones relacionadas con el régimen de la insolvencia	
A.	Finalización y aprobación de las revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza	

	B.	Finalización y aprobación de las recomendaciones legislativas sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia
	C.	Finalización de las revisiones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial
	D.	Informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo V
VI.		Examen de cuestiones relacionadas con la contratación pública
VII.		Solución de controversias en línea: informe sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo III
VIII.		Comercio electrónico: informe sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo IV
IX.		Asistencia técnica: reforma legislativa.
	X.	Fomento de los modos necesarios para asegurar una interpretación y una aplicación uniformes de los textos jurídicos de la CNUDMI.
	XI.	Situación y promoción de los textos de la CNUDMI
XII.		Coordinación y cooperación.
	A.	Observaciones generales
	B.	Coordinación y cooperación en materia de garantías reales
	C.	Informes de otras organizaciones internacionales.
	D.	Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales invitadas a asistir a los períodos de sesiones de la CNUDMI y de sus grupos de trabajo
XIII.		Centros regionales de la CNUDMI
XIV.		Función que desempeña la CNUDMI en el fomento del estado de derecho a nivel nacional e internacional
	A.	Introducción
	B.	Novedades pertinentes desde el 45º período de sesiones de la Comisión
	C.	Observaciones formuladas a la Asamblea General sobre las funciones actuales de la CNUDMI en la promoción del estado de derecho
XV.		Labor prevista y posible labor futura, entre otras cosas en los ámbitos del arbitraje y la conciliación, el fraude comercial, el comercio electrónico, el régimen de la insolvencia, el derecho contractual internacional, las microfinanzas, la solución de controversias en línea, la contratación pública y el desarrollo de infraestructuras, incluida la colaboración entre el sector público y el sector privado, y las garantías reales
XVI.		Resoluciones pertinentes de la Asamblea General
XVII.		Otros asuntos
	A.	Derecho a actas resumidas
	B.	Programa de pasantías
	C.	Evaluación del papel de la Secretaría en la facilitación de la labor de la Comisión

- XVIII. Lugar y fecha de futuras reuniones
- A. El 47° período de sesiones de la Comisión
- B. Períodos de sesiones de los grupos de trabajo

Anexos

- I. Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado.
- II. Modificación del artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI
- III. Lista de documentos presentados a la Comisión en su 46° período de sesiones

I. Introducción

1. El presente informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) abarca la labor realizada durante el 46º período de sesiones de la Comisión, celebrado en Viena del 8 al 26 de julio de 2013.
2. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1966, este informe se somete a la consideración de la Asamblea y se presenta también a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para que formule observaciones.

II. Organización del período de sesiones

A. Apertura del período de sesiones

3. El 46º período de sesiones de la Comisión se declaró abierto el 8 de julio de 2013.

B. Composición y asistencia

4. En su resolución 2205 (XXI), la Asamblea General estableció la Comisión con 29 Estados elegidos por ella. En su resolución 3108 (XXVIII), de 12 de diciembre de 1973, la Asamblea aumentó de 29 a 36 el número de miembros de la Comisión. En su resolución 57/20, de 19 de noviembre de 2002, la Asamblea volvió a aumentar ese número, que pasó de 36 a 60 Estados. Los actuales miembros de la Comisión, elegidos el 3 de noviembre de 2009, el 15 de abril de 2010, el 14 de noviembre de 2012 y el 14 de diciembre de 2012, son los Estados siguientes, cuyo mandato expira el último día antes del comienzo del período de sesiones anual de la Comisión del año que se indica¹: Alemania (2019), Argelia (2016), Argentina (2016), Armenia (2019), Australia (2016), Austria (2016), Belarús (2016), Botswana (2016), Brasil (2016), Bulgaria (2019), Camerún (2019), Canadá (2019), China (2019), Colombia (2016), Côte d'Ivoire (2019), Croacia (2016), Dinamarca (2019), Ecuador (2019), El Salvador (2019), España (2016), Estados Unidos de América (2016), Federación de Rusia (2019), Fiji (2016), Filipinas (2016), Francia (2019), Gabón (2016), Georgia (2015), Grecia (2019), Honduras (2019),

¹ De conformidad con la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, los miembros de la Comisión se eligen para un período de seis años. De los actuales miembros, 28 fueron elegidos por la Asamblea el 3 de noviembre de 2009, 2 fueron elegidos por la Asamblea el 15 de abril de 2010, 29 fueron elegidos por la Asamblea el 14 de noviembre de 2012 y 1 fue elegido por la Asamblea el 14 de diciembre de 2012. En su resolución 31/99, la Asamblea modificó las fechas de inicio y terminación del mandato de los miembros de la Comisión al decidir que estos asumieran sus funciones al comienzo del primer día del período ordinario anual de sesiones de la Comisión que se celebrara inmediatamente después de su elección y que sus mandatos expiraran el último día antes de la apertura del séptimo período ordinario anual de sesiones de la Comisión que se celebrara después de su elección. Los seis Estados miembros siguientes, elegidos por la Asamblea el 3 de noviembre de 2009, acordaron alternar entre ellos sus funciones como miembros hasta 2016: Belarús (2010-2011, 2013-2016), República Checa (2010-2013, 2015-2016), Polonia (2010-2012, 2014-2016), Ucrania (2010-2014), Georgia (2011-2015) y Croacia (2012-2016).

Hungría (2019), India (2016), Indonesia (2019), Irán (República Islámica del) (2016), Israel (2016), Italia (2016), Japón (2019), Jordania (2016), Kenya (2016), Kuwait (2019), Liberia (2019), Malasia (2019), Mauricio (2016), Mauritania (2019), México (2019), Namibia (2019), Nigeria (2016), Pakistán (2016), Panamá (2019), Paraguay (2016), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2019), República de Corea (2019), Sierra Leona (2019), Singapur (2019), Suiza (2019), Tailandia (2016), Turquía (2016), Ucrania (2014), Uganda (2016), Venezuela (República Bolivariana de) (2016) y Zambia (2019).

5. Con excepción de Armenia, Botswana, Camerún, Côte d'Ivoire, Fiji, Gabón, Grecia, Jordania, Liberia, Mauritania, Sierra Leona y Zambia, todos los miembros de la Comisión estuvieron representados en el período de sesiones.

6. Asistieron al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Afganistán, Angola, Bélgica, Bolivia (Estado Plurinacional de), Burkina Faso, Chile, Cuba, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Guatemala, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Qatar, República Checa, República Dominicana, Rumania, Senegal, Suecia y Viet Nam.

7. Asistieron también observadores del Estado de Palestina y la Unión Europea.

8. Asistieron, además, observadores de las siguientes organizaciones internacionales:

a) *Sistema de las Naciones Unidas*: Banco Mundial, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Comisión Económica para Europa y Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo;

b) *Organizaciones intergubernamentales*: Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad Económica de Eurasia, Corte Permanente de Arbitraje, Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) y Organización Mundial de Aduanas;

c) *Organizaciones no gubernamentales invitadas*: American Bar Association, Asociación de Arbitraje de los Estados Unidos y Centro Internacional para la Resolución de Disputas, Asociación Europea de Estudiantes de Derecho, Asociación Internacional de Abogados, Association Suisse de l'Arbitrage, Center for International Environmental Law, Centro de Estudios Jurídicos Internacionales, Centro Nacional de Investigaciones Jurídicas para el Libre Comercio, Corte de Arbitraje de Madrid, Federación Interamericana de Abogados, Foro de Conciliación y Arbitraje Internacionales, Institute of International Banking Law and Practice, Instituto de Arbitraje Internacional, Instituto de Derecho y Tecnología (Universidad de Masaryk), Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, International Insolvency Institute, International Swaps and Derivatives Association, Internacional Women's Insolvency and Restructuring Confederation, Moot Alumni Association, New York State Bar Association y Unión Internacional de Abogados.

9. La Comisión acogió con beneplácito la participación de organizaciones no gubernamentales internacionales con conocimientos especializados en cuestiones relacionadas con los principales temas del programa. Su participación era decisiva para la calidad de los textos preparados por la Comisión, por lo que esta pidió a la Secretaría que siguiera invitando a esas organizaciones a sus períodos de sesiones.

C. Elección de la Mesa

10. La Comisión eligió a las siguientes personas para que integraran la Mesa:

<i>Presidente:</i>	Michael Schöll (Suiza)
<i>Vicepresidentes:</i>	Rodrigo Labardini Flores (México) Salim Moollan (Mauricio) Hrvoje Sikirić (Croacia)
<i>Relator:</i>	Sukpuck Phongsathit (Tailandia)

D. Programa

11. El programa del período de sesiones, aprobado por la Comisión en su 958ª sesión, celebrada el 8 de julio de 2013, fue el siguiente:

1. Apertura del período de sesiones.
2. Elección de la Mesa.
3. Aprobación del programa.
4. Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación:
 - a) Finalización y aprobación del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado;
 - b) Examen de instrumentos relativos a la aplicabilidad del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia a la solución de controversias surgidas en el marco de tratados de inversión ya existentes;
 - c) Preparación de una guía sobre la Convención de Nueva York de 1958;
 - d) Concursos de arbitraje comercial internacional simulado.
5. Examen de cuestiones relacionadas con las garantías reales:
 - a) Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación de un registro de garantías reales;
 - b) Informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo VI;
 - c) Coordinación en el ámbito de las garantías reales.
6. Examen de cuestiones relacionadas con el régimen de la insolvencia:
 - a) Finalización y aprobación de las revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza;
 - b) Finalización y aprobación de las recomendaciones legislativas sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia;

- c) Finalización y aprobación de las revisiones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial;
 - d) Informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo V.
- 7. Examen de cuestiones relacionadas con la contratación pública.
- 8. Solución de controversias en línea: informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo III.
- 9. Comercio electrónico: informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo IV.
- 10. Asistencia técnica para la reforma legislativa.
- 11. Fomento de los modos necesarios para asegurar una interpretación y una aplicación uniformes de los textos jurídicos de la CNUDMI.
- 12. Situación y promoción de los textos jurídicos de la CNUDMI.
- 13. Coordinación y cooperación:
 - a) Observaciones generales;
 - b) Informes de otras organizaciones internacionales;
 - c) Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales invitadas a asistir a los períodos de sesiones de la CNUDMI y de sus grupos de trabajo.
- 14. Centros regionales de la CNUDMI.
- 15. Función que desempeña la CNUDMI en el fomento del estado de derecho a nivel nacional e internacional.
- 16. Labor prevista y posible labor futura, entre otras cosas en los ámbitos del arbitraje y la conciliación, el fraude comercial, el comercio electrónico, el régimen de la insolvencia, el derecho contractual internacional, las microfinanzas, la solución de controversias en línea, la contratación pública y el desarrollo de infraestructuras, incluida la colaboración entre el sector público y el sector privado, y las garantías reales.
- 17. Resoluciones pertinentes de la Asamblea General.
- 18. Otros asuntos.
- 19. Lugar y fecha de futuras reuniones.
- 20. Aprobación del informe de la Comisión.

E. Aprobación del informe

12. En sus sesiones 965^a, celebrada el 11 de julio de 2013, 972^a, celebrada el 17 de julio de 2013, 975^a, celebrada el 19 de julio de 2013, y 982^a y 983^a, celebradas el 26 de julio de 2013, la Comisión aprobó por consenso el presente informe.

III. Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación

A. Finalización y aprobación de una versión revisada del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado

1. Introducción

13. La Comisión recordó la decisión que había adoptado en su 41º período de sesiones², celebrado en 2008, y de nuevo en su 43º período de sesiones³, celebrado en 2010, de que, una vez concluida la revisión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, se abordara, con carácter prioritario, el tema de la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado⁴. En su 43º período de sesiones, la Comisión encomendó a su Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) la tarea de preparar una norma jurídica sobre ese tema. En su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión reiteró el compromiso que había expresado en su 41º período de sesiones acerca de la importancia de que se garantizara la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado⁵.

14. En su período de sesiones en curso, la Comisión tuvo a su disposición los informes del Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) sobre la labor de sus períodos de sesiones 57º, celebrado en Viena del 1 al 5 de octubre de 2012, y 58º, celebrado en Nueva York del 4 al 8 de febrero de 2013 (A/CN.9/760 y A/CN.9/765, respectivamente). También tuvo ante sí el texto del proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado con la redacción resultante de la tercera lectura realizada por el Grupo de Trabajo en su 58º período de sesiones, que figura en el documento A/CN.9/783.

15. La Comisión tomó nota del resumen de las deliberaciones relativas al Reglamento sobre la Transparencia que habían tenido lugar desde el 53º período de sesiones del Grupo de Trabajo, celebrado en Viena, del 4 al 8 de octubre de 2010. También tomó nota de las observaciones presentadas por los gobiernos en relación con el Reglamento sobre la Transparencia y con las modificaciones propuestas al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010), que se recogen en el documento A/CN.9/787 y sus adiciones.

² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1)*, párr. 314.

³ *Ibid.*, sexagésimo quinto período de sesiones, *Suplemento núm. 17 (A/65/17)*, párr. 190.

⁴ Véase el texto del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (1976) en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/31/17)*. Véase el texto del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010) en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17)*, anexo I.

⁵ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17)*, párrs. 200 a 202.

2. Examen del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado

Proyecto de artículo 1: Ámbito de aplicación

16. Se recordó a la Comisión que, en su 58º período de sesiones, el Grupo de Trabajo había expresado de forma oficial y unánime su apoyo a una propuesta de transacción revisada (A/CN.9/765, párrs. 75 y 78) que incluía el artículo 1, relativo al ámbito de aplicación. Sobre esa base, la Comisión examinó las sugerencias relativas a la redacción que figuran en los párrafos 6 a 10 del documento A/CN.9/783.

Observaciones generales

17. Se convino en mantener la estructura del artículo 1 y el orden de sus párrafos.

Parte introductoria del párrafo 2) y nuevo párrafo 9)

18. La Comisión observó que los párrafos 1) y 2) se referían a la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. La aplicación del Reglamento sobre la Transparencia junto con otros reglamentos de arbitraje se trataba de forma indirecta en el párrafo 7). En aras de la coherencia con esa disposición, y a fin de aclarar que el Reglamento sobre la Transparencia podía aplicarse independientemente del reglamento de arbitraje que fuera aplicable, la Comisión examinó si deberían añadirse en la parte introductoria del párrafo 2) las siguientes palabras entre corchetes: “[o [ii) los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en el marco de un tratado, con arreglo a otros reglamentos de arbitraje o con carácter especial]”.

19. Se expresó la opinión de que el Reglamento sobre la Transparencia debía poder utilizarse en todo tipo de procedimientos de arbitraje, tanto los entablados con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI como los entablados con arreglo a reglamentos de instituciones arbitrales o con carácter especial. La Comisión tomó nota de las observaciones formuladas por instituciones arbitrales que figuraban en el documento A/CN.9/WG.II/WP.173. Las instituciones arbitrales señalaban que sus reglas institucionales de arbitraje podían aplicarse en conjunción con el Reglamento sobre la Transparencia, si las partes en el tratado o las partes litigantes así lo decidieran.

20. La Comisión convino en que, en aras de la claridad, la posible aplicación del Reglamento sobre la Transparencia junto con otros reglamentos de arbitraje o en arbitrajes de carácter especial debía preverse explícitamente en el Reglamento sobre la Transparencia. Para apoyar ese enfoque se señaló además que el mandato de la CNUDMI consistía en preparar una norma jurídica sobre la transparencia que pudiera aplicarse universalmente, sin limitar su aplicación a los arbitrajes entablados con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

21. La Comisión convino también en que la cuestión no debía tratarse en el párrafo 2), en que se distinguía entre la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia con arreglo a los tratados vigentes y su aplicación conforme a tratados futuros, en ambos casos cuando se entablaba un procedimiento arbitral entre un inversionista y un Estado conforme al Reglamento de Arbitraje de

la CNUDMI. Se convino en que habría que tener en cuenta otras cuestiones cuando se tratara de arbitrajes entablados con arreglo a otros reglamentos o de carácter especial.

22. Tras deliberar, la Comisión decidió incluir en el artículo 1 un párrafo nuevo, el párrafo 9), con el siguiente texto: “El presente Reglamento podrá aplicarse en arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con reglamentos que no sean el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, o en procedimientos de carácter especial”. Además, se añadiría un subepígrafe nuevo titulado “Aplicación en arbitrajes no regulados por la CNUDMI”. Se aclaró que esa disposición, que tenía por objeto indicar la aplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia a procesos de arbitraje entablados con arreglo a otros reglamentos o a procesos de carácter especial, se aplicaría con sujeción al principio de la autonomía de las partes, es decir, cuando las partes en el tratado o las partes litigantes así lo hubieran acordado.

23. Conforme a esa decisión, se convino en que la parte introductoria del párrafo 2) dijera lo siguiente: “Con respecto a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado celebrado antes de (*fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia*), este Reglamento solamente se aplicará si:”.

Párrafo 2) b)

24. Se señaló que la expresión “Estado de origen del inversionista”, que figuraba en el párrafo 2) b), era poco habitual y podría plantear controversias sobre la jurisdicción y la nacionalidad en relación con la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia. A ese respecto, se sugirió sustituir la fórmula “en el caso de un tratado multilateral, el Estado de origen del inversionista y el Estado demandado” por la fórmula “en el caso de un tratado multilateral, las partes pertinentes”.

25. Se respondió que la expresión “las partes pertinentes” no sería adecuada en relación con los procedimientos entablados con arreglo a tratados multilaterales como el Tratado sobre la Carta de la Energía⁶, en los que podía ser difícil identificar a las “partes pertinentes” y resultaría más sencillo usar el criterio del “Estado demandado”.

26. A fin de alcanzar un resultado más neutral, que cabía suponer que era lo que se buscaba con la referencia al “Estado de origen del inversionista”, se propuso sustituir la expresión por “el Estado del demandante”. Se afirmó que con esa formulación: a) se evitaba la necesidad de adoptar una determinación basada en la jurisdicción o la nacionalidad haciendo referencia al Estado en el que el demandante se hubiera acogido a la protección que le otorgaba el tratado; y b) se evitaba el riesgo de que pudieran surgir problemas relacionados con el término “inversionista” y, por ejemplo, con el hecho de que se hubiera realizado una inversión que lo calificara como tal o no. Se indicó que, si bien esos problemas podían plantearse en una etapa jurisdiccional del procedimiento, no se pretendía invocarlos en relación con la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia.

⁶ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 2080, núm. 36116.

27. Tras deliberar, la Comisión convino en sustituir la expresión “el Estado de origen del inversionista”, que aparecía en el párrafo 2) b), por la expresión “el Estado del demandante”.

Párrafo 3) b)

28. Se dijo que la formulación “sin menoscabar el objetivo de transparencia del Reglamento”, que figuraba en el párrafo 3) b), podría reformularse de modo más positivo y neutral.

29. Se propuso sustituir las palabras “sin menoscabar” por las palabras “y se logre”.

30. Se formuló una segunda propuesta de sustituir la frase “sin menoscabar” por la frase “y si es coherente con”, de manera que el párrafo 3) b) dijera: “b) el tribunal arbitral, al margen de las facultades discrecionales que le confieren algunas disposiciones de este Reglamento, estará facultado para adaptar los requisitos de cualquiera de sus disposiciones concretas a las circunstancias del caso si esa adaptación resulta necesaria para que el arbitraje se lleve a cabo de una forma práctica y si es coherente con el objetivo de transparencia del Reglamento”.

31. Se acordó que era conveniente evitar el juicio de valor asociado a palabras como “lograr” o “menoscabar”. En consecuencia, se acordó aprobar la frase “y si es coherente con”.

32. Se convino, además, que el párrafo 3) b) debía hacerse compatible con otras disposiciones del reglamento en las que se otorgaba al tribunal arbitral poder o discrecionalidad después de celebrar consultas con las partes litigantes. La incorporación en el párrafo 3) b) de una formulación en ese sentido quedó sujeta a un examen ulterior.

33. También se indicó que si se contemplaba que el tribunal arbitral celebrara tales consultas debía señalarse explícitamente en el reglamento, y se pidió a la Secretaría que revisara el texto del reglamento en su totalidad y asegurara que fuese coherente a ese respecto.

34. Tras ese examen, y después de aclarar que en todo el Reglamento sobre la Transparencia, cuando se pretendiera que el tribunal arbitral consultara con las partes litigantes, ello debía especificarse explícitamente, se acordó insertar en el párrafo 3) b) las palabras “tras celebrar consultas con las partes litigantes” después de las palabras “a las circunstancias del caso”.

Notas a pie de página

35. Se sugirió que se modificaran las notas a pie de página del artículo 1, párrafo 1), a fin de que la frase “tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas” pudiera aplicarse también a los territorios que tal vez fueran partes en el tratado pero no estuvieran comprendidos en la definición de acuerdo con su texto actual. Como parte de esa propuesta, se sugirió que se suprimiera en la segunda nota a pie de página la definición de “‘parte en el tratado’ o ‘Estado’”. En respuesta a ello, se recordó que la palabra “Estado” se utilizaba en todo el reglamento y que, por consiguiente, se necesitaba una segunda nota a pie de página del párrafo 1) para garantizar que, entre otras cosas, las organizaciones regionales de integración económica quedaran incluidas en esa definición.

36. Se sugirió también que se armonizara más la definición de “tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas”, contenida en la primera nota a pie de página, con la definición de “tratado” que figuraba en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados⁷, con la adaptación necesaria a los fines del Reglamento sobre la Transparencia.

37. Posteriormente se presentó otra propuesta, según la cual se modificaría la primera nota a pie de página para que dijera lo siguiente: “A los fines del Reglamento sobre la Transparencia, por “tratado” se entenderá, en sentido amplio, todo tratado bilateral o multilateral que contenga disposiciones sobre la protección de las inversiones o los inversionistas y el derecho de los inversionistas a recurrir al arbitraje contra las partes en el tratado, incluidos los tratados comúnmente denominados acuerdos de libre comercio, acuerdos de integración económica, acuerdos marco o de cooperación en materia de comercio e inversiones o tratados bilaterales de inversión”.

38. Esa propuesta fue aceptada, y se convino en que el texto del párrafo 37 del presente documento sustituyera a la primera nota a pie de página. Además, dado que la definición contenida en la nota al pie se refería al término “tratado”, y no a la expresión “tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas”, se acordó que en el texto del párrafo 1), la referencia a la nota al pie se colocaría después de la palabra “(‘tratado’)

39. En relación con la segunda nota a pie de página, se convino en que, en la versión en inglés, debía insertarse “a” delante de la palabra “State”, y que las palabras “se aplica igualmente a” debían sustituirse por las palabras “incluye, por ejemplo,”.

Aprobación del artículo 1

40. Con las modificaciones convenidas y reflejadas en los párrafos 16 a 39 del presente documento, la Comisión aprobó el contenido del artículo 1.

Proyecto de artículo 2: Publicación de información tras el inicio del procedimiento arbitral

41. Se señaló que quizá fuera necesario prever un mecanismo de control en el artículo 2, a fin de que la institución encargada del archivo dispusiera de cierto margen de discrecionalidad cuando una parte litigante impugnara la aplicabilidad del reglamento, o cuando se presentara una reclamación sin fundamento o abusiva. También se señaló que ese mecanismo tal vez podría preverse en las directrices relativas al archivo.

42. Se recordó que en el artículo 2 se restringía deliberadamente la información que se podía publicar en la fase de notificación para incluir únicamente la información fáctica que figurara en ese artículo, de modo que la función de archivo no exigiera hacer uso de discrecionalidad ni adoptar decisiones. El tribunal arbitral resolvería entonces cualquier desacuerdo que surgiera entre las partes litigantes antes de que se enviaran más documentos al archivo. La Comisión entendía que se esperaba que el archivo, cuando recibiera información, publicara esa información con arreglo a lo establecido en el reglamento.

⁷ *Ibid.*, vol. 1155, núm. 18232.

Aprobación del artículo 2

43. Tras deliberar, la Comisión aprobó el contenido del artículo 2.

Proyecto de artículo 3: Publicación de documentos*Párrafo 3)*

44. Se consideró si se debía mantener el texto que figuraba entre corchetes en el párrafo 3). A ese respecto, se señaló que, aunque desde un punto de vista jurídico, dicho texto, en el que se daba un ejemplo de cómo el tribunal arbitral podía proporcionar información en virtud del citado párrafo, no era necesario, sí ofrecía orientación útil a los tribunales arbitrales.

45. Tras un debate, se convino en que se debía mantener el texto y suprimir los corchetes.

Párrafo 5)

46. Se señaló que el texto del párrafo 5) en su forma actual no era suficientemente claro. Se indicó además que el párrafo 5) debía abarcar solo las solicitudes formuladas en virtud del párrafo 3) del artículo 3, pero no las presentadas en virtud del párrafo 2), ya que los documentos relacionados con este último párrafo se publicarían automáticamente de todas formas.

47. Tras deliberar, la Comisión decidió proponer la siguiente redacción para el párrafo 5): “Las personas que reciban acceso a documentos con arreglo a lo establecido en el párrafo 3 sufragarán los gastos administrativos que conlleve facilitar el acceso de esas personas a los documentos, como los gastos de fotocopiado o envío de los documentos a esas personas, pero no los gastos administrativos que conlleve facilitar el acceso del público a esos documentos por conducto del archivo”.

48. Se señaló que era necesario repetir las palabras “esas personas” a fin de aclarar que los gastos pertinentes que cabía sufragar eran únicamente los efectuados para facilitar los documentos a la persona que formulara la solicitud en cuestión, y no, por ejemplo, los gastos de fotocopiado o envío relativos a la presentación de documentos ante el registro.

Aprobación del artículo 3

49. Una delegación señaló que le preocupaba que el artículo 3 pudiera dar pie a la publicación de un gran volumen de documentación en la que debieran suprimirse partes del texto, lo cual podría hacer que aumentara considerablemente el costo y la duración de los arbitrajes en materia de inversiones.

50. Tras deliberar, la Comisión aprobó el contenido del artículo 3 con las modificaciones que se indican en los párrafos 44 a 48 del presente documento.

Proyecto de artículo 4: Escritos presentados por terceros*Párrafo 2)*

51. En cuanto a la redacción de la parte introductoria del párrafo 2), se acordó eliminar la palabra “such” de la versión en inglés y cambiar la expresión “que pueda haber determinado” por “que haya determinado”.

52. También se acordó sustituir las palabras “como, por ejemplo, la financiación de aproximadamente el 20% del total de sus operaciones anualmente” con el siguiente texto: “(por ejemplo, la financiación de aproximadamente el 20% del total de sus operaciones anualmente)”.

Párrafo 3)

53. Se sugirió que se ajustara la redacción del párrafo 3) a la formulación de la segunda oración del artículo 5, párrafo 2) y, por tanto, que se sustituyeran las palabras “Para determinar si permite la presentación de un escrito” del artículo 4, párrafo 3), por las palabras “En el ejercicio de sus facultades discrecionales en cuanto a aceptar o no tales escritos”.

54. Se respondió que esos dos párrafos tenían propósitos diferentes. En el artículo 5, párrafo 2), se otorgaban facultades discrecionales a los tribunales arbitrales para aceptar escritos o no aceptarlos, mientras que en el artículo 4, párrafo 3), se enumeraba una lista de factores que el tribunal arbitral debía tener en cuenta a la hora de determinar si permitía la presentación de un escrito. En consecuencia, se convino en que la redacción del artículo 4, párrafo 3), no debía modificarse y se aprobó el contenido del artículo 4, párrafo 3), en la forma en que figuraba en el párrafo 17 del documento A/CN.9/783.

Párrafos 5) y 6)

55. Se acordó sustituir las palabras “el escrito”, de los párrafos 5) y 6), por “los escritos”, en aras de la coherencia de esos párrafos con las disposiciones equivalentes del artículo 5, párrafos 4) y 5).

Aprobación del artículo 4

56. Tras deliberar, la Comisión aprobó el contenido del artículo 4, con las modificaciones acordadas que se señalan en los párrafos 51 a 55 del presente documento.

Proyecto de artículo 5: Escritos presentados por partes en el tratado no litigantes*Párrafos 1) y 2)*

57. Con respecto a la redacción, se acordó cambiar en los párrafos 1) y 2) las palabras “aceptará” y “aceptar” por “permitirá” y “permitir”, para mantener la coherencia con la terminología utilizada en el artículo 4.

Párrafo 2)

58. Se expresó preocupación por que, en virtud del párrafo 2), existiera el riesgo de que el escrito presentado por el Estado parte en el tratado no litigante entrara casi en el ámbito de la protección diplomática. Se aclaró que ese riesgo correspondía

solamente al párrafo 2). Se señaló que el párrafo 1) se refería a la presentación de escritos sobre cuestiones relativas a la interpretación del tratado por partes no litigantes. En relación con la interpretación del tratado, se dijo que el Estado parte en el tratado que no fuera parte litigante podía aportar una perspectiva diferente a la interpretación del tratado, inclusive el acceso a los *travaux préparatoires*, de los que de otro modo el tribunal arbitral tal vez no dispondría, de forma que se evitarían interpretaciones parciales basadas en la argumentación del Estado demandado.

59. En relación con el párrafo 2), se aclaró que no se había pretendido que mediante esa disposición se permitiera la presentación de escritos en los que se apoyara la reclamación de un inversionista de modo tal que equivaliera a protección diplomática. Una delegación opinó que la palabra “equivaler” podría no servir de orientación suficiente al tribunal arbitral. Esa opinión no fue respaldada.

60. Algunas delegaciones apoyaron que no se modificara el párrafo 2).

61. Otras delegaciones apoyaron que se suprimiera el párrafo 2) o que se le incluyera un texto explícito para aclarar que tal disposición no debía permitir que un Estado ofreciera argumentos en un procedimiento de arbitraje en apoyo de un inversionista que fuera nacional de ese Estado, lo cual rebasaría el alcance previsto de la disposición y equivaldría a protección diplomática. A ese respecto se formuló la propuesta de añadir al final del párrafo 2) el siguiente texto: “, y la necesidad de evitar que una parte no litigante presente escritos en los que apoye la reclamación de un inversionista de modo tal que equivalga a protección diplomática”.

62. Las delegaciones expresaron opiniones divergentes sobre si el propósito de ese texto estaba en realidad previsto en el artículo 4, párrafo 3) b), del reglamento, al que, en todo caso, estaba sujeto el artículo 5, párrafo 2). Después de debatir la cuestión, la Comisión expresó el parecer de que, incluso si el asunto estaba ya previsto en el artículo 4, párrafo 3) b), a fin de evitar dudas convendría incluir una disposición específica sobre esa cuestión en el artículo 5, párrafo 2). En tal sentido, se formuló otra propuesta consistente en incluir al final del párrafo 2) una nueva oración que dijera: “A fin de evitar dudas, en el ejercicio de sus facultades discrecionales en cuanto a permitir o no que se presenten tales escritos, el tribunal arbitral tendrá en cuenta la necesidad de evitar la presentación por una parte no litigante de escritos en que se apoye la reclamación de un inversionista de modo tal que equivalga a protección diplomática”. La Comisión acordó seguir examinando esa propuesta en una etapa ulterior.

63. Tras examinar más a fondo la cuestión, la Comisión convino en añadir la siguiente frase al final del párrafo 2): “, y, a fin de aportar una mayor certeza, la necesidad de evitar la presentación de escritos en que se apoye la reclamación de un inversionista de modo tal que equivalga a protección diplomática”.

64. La Comisión consideró que las palabras introductorias del artículo 4, párrafo 3), y el artículo 5, párrafo 2), podían armonizarse porque, según se señaló, el razonamiento expuesto en los párrafos 53 y 54 del presente documento ya no eran aplicables a la luz de esa modificación. A ese respecto, la Comisión examinó el párrafo 40 del documento A/CN.9/760, pero estuvo de acuerdo en que cuando en el reglamento se invitaba a un tribunal a que ejerciera sus facultades discrecionales, se aplicaban claramente, de hecho, los criterios enumerados en el artículo 1, párrafo 4), independientemente de que se utilizaran las palabras “facultades discrecionales”. En el artículo 5, párrafo 2), la Comisión convino en sustituir las

palabras “En el ejercicio de sus facultades discrecionales en cuanto a aceptar o no tales escritos”, por la frase “Para determinar si permite la presentación de tales escritos”.

Aprobación del artículo 5

65. Tras deliberar, la Comisión aprobó el contenido del artículo 5, con las modificaciones acordadas que se señalan en los párrafos 57 a 64 del presente documento.

Proyecto de artículo 6: Audiencias

66. Se recordó a la Comisión que, en su 58º período de sesiones, el Grupo de Trabajo había expresado oficialmente su apoyo unánime a la propuesta de transacción revisada, que incluía el artículo 6, relativo a las audiencias públicas.

67. En respuesta a la preocupación por que el artículo 6 pudiera ser ambiguo en cuanto a si las partes litigantes podían acordar la celebración de audiencias en privado, se aclaró que el principio enunciado en el párrafo 1) era que las audiencias debían ser públicas, con sujeción únicamente a lo dispuesto en los párrafos 2) y 3) del artículo 6. Se recordó que el Grupo de Trabajo había examinado ampliamente la cuestión de si las partes litigantes podían acordar la celebración de audiencias en privado, y no había aceptado esa propuesta. Se señaló que el artículo 6 debía considerarse a la luz de lo dispuesto en su artículo 1.

Aprobación del artículo 6

68. Tras las correspondientes deliberaciones, se aprobó sin cambios el contenido del artículo 6.

Proyecto de artículo 7: Excepciones a la norma de la transparencia

69. Se recordó a la Comisión que, en su 58º período de sesiones, el Grupo de Trabajo había expresado de forma oficial y unánime su apoyo a la propuesta de transacción revisada, que incluía el artículo 7 relativo a las excepciones a la norma de la transparencia. Se recordó además que el Grupo de Trabajo había convenido en limitar las excepciones a esa norma a la protección de la información confidencial o protegida (artículo 7, párrafos 1) a 5)) y a la protección de la integridad del proceso arbitral (artículo 7, párrafos 6) y 7)) (A/CN.9/765, párrafos 75 y 78).

Observaciones generales

70. Se acordó mantener la estructura y el orden de los párrafos del artículo 7.

“Terceros” - “Partes no litigantes” - “Público”

71. Se sugirió que se suprimiera la expresión “partes en el tratado no litigantes” en los párrafos 1), 3) y 5) por considerar que la expresión “el público” era ya lo suficientemente amplia.

72. La Comisión señaló que entendía que la expresión “el público” se utilizaba en el reglamento de forma genérica, con el fin de abarcar a los “terceros” a que se hacía referencia en el artículo 4 y a las “partes no litigantes” mencionadas en el artículo 5. La Comisión consideró si era necesario aclarar esta cuestión en el reglamento,

mediante una nota de pie de página o una explicación en el texto del propio reglamento.

73. En respuesta a ello se señaló que la información que se pusiera a disposición del público se publicaría en el sitio web del archivo y, por consiguiente, la expresión “el público” debía incluir tanto a los “terceros” como a las “partes en el tratado no litigantes”.

74. Tras deliberar, la Comisión convino en que la expresión “el público” tenía carácter genérico y, tal como se empleaba en el reglamento, incluía tanto a los terceros como a las partes en el tratado no litigantes. Así pues, se acordó aprobar la sugerencia indicada en el párrafo 71 del presente documento.

Párrafo 3)

75. Se sugirió colocar la última frase del párrafo 3) al principio de dicho párrafo. Esa propuesta no fue respaldada, debido a que la finalidad de la última frase de esa disposición era hacer referencia a las situaciones en que las partes no estuvieran de acuerdo con la supresión de información confidencial o protegida.

76. En aras de la coherencia de la redacción, la Comisión convino en sustituir las palabras “en consulta”, que figuraban delante de las palabras “con las partes”, por las palabras “tras celebrar consultas” en la parte introductoria del párrafo 3).

Párrafo 5)

77. Se sugirió que se añadieran las palabras “su interés público o” delante de “sus intereses de seguridad”, ya que la expresión “interés público” se utilizaba con mayor frecuencia en algunas jurisdicciones que la expresión “intereses de seguridad”. La propuesta no fue respaldada.

Aprobación del artículo 7

78. Tras deliberar, la Comisión aprobó el contenido del artículo 7, con las modificaciones acordadas que se señalan en los párrafos 70 a 76 del presente documento.

Proyecto de artículo 8: Archivo de la información publicada

79. La Comisión recordó la decisión unánime del Grupo de Trabajo en el sentido de que la secretaría de la CNUDMI era la entidad natural y preferida para ejercer la función de archivo de la información publicada conforme al reglamento. Se afirmó que las Naciones Unidas, como entidad neutral y universal, y su Secretaría, órgano independiente según lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas, deberían asumir las funciones esenciales de archivo conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Transparencia, por ser una institución pública directamente responsable de prestar servicios relativos a sus propias normas jurídicas y garantizar el funcionamiento adecuado de esas normas.

80. La Comisión expresó su opinión firme y unánime de que la secretaría de la CNUDMI debería desempeñar la función de archivo de la transparencia. La Comisión puso de relieve que la labor de la CNUDMI era crucial para promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y que las normas

legislativas elaboradas por la CNUDMI contribuían directamente a promover el desarrollo sostenible.

81. A ese respecto, se afirmó que el objetivo del archivo de la transparencia era fomentar el desarrollo y el bienestar económicos. La Comisión expresó su acuerdo con la idea de que la transparencia era uno de los principales valores de la buena gobernanza y el estado de derecho y que, por tanto, su labor en ese ámbito fomentaba el bienestar de los países en desarrollo. También se observó que la mención a las Naciones Unidas en la lista de las organizaciones internacionales que cumplían los requisitos para recibir fondos de asistencia oficial para el desarrollo abarcaba a la CNUDMI, en su calidad de comisión permanente de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

82. La Comisión encomendó a la Secretaría que, por conducto de las Comisiones Quinta y Sexta de la Asamblea General, buscara la financiación necesaria para poder ejercer la función de archivo de la transparencia. Varias delegaciones señalaron que la solicitud de financiación adicional de la secretaría de la CNUDMI se debería formular de modo que no supusiera un costo adicional en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

83. La Comisión acordó que la fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia sería el 1 de abril de 2014. Se había elegido esa fecha a fin de dar a la Secretaría tiempo suficiente para obtener los fondos del presupuesto ordinario o fondos extrapresupuestarios que le permitieran cumplir el mandato descrito en el párrafo 79 del presente documento.

84. Tras deliberar, la Comisión convino en que el artículo 8 del reglamento se modificara del siguiente modo: “El archivo de la información publicada conforme al Reglamento sobre la Transparencia será el Secretario General de las Naciones Unidas o una institución nombrada por la CNUDMI”.

85. Se afirmó que con la redacción propuesta, en caso de que la secretaría de la CNUDMI no pudiera obtener financiación de la Asamblea General ni financiación extrapresupuestaria antes de la entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia el 1 de abril de 2014, otra institución, designada por la Comisión en su período de sesiones actual, podría ejercer la función de archivo hasta que la secretaría de la CNUDMI obtuviera los recursos necesarios.

86. Se puso de relieve que toda institución designada por la Comisión para desempeñar la función de archivo en esas circunstancias lo haría de manera temporal y a modo de refuerzo, y únicamente hasta que la secretaría de la CNUDMI hubiera obtenido los recursos necesarios. Se aclaró que, una vez que la secretaría de la CNUDMI comunicara que había obtenido los recursos necesarios, la institución designada proporcionaría todos los datos de que dispusiera o que hubiera publicado en el ejercicio de sus funciones como archivo y dejaría de ejercer como tal en ese momento, sin costo alguno para la CNUDMI ni su secretaría.

87. Se recordó que dos instituciones, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, habían expresado su disposición de asumir la función de archivo en caso de que la secretaría de la CNUDMI no contara con los recursos necesarios para hacerlo. Ambas instituciones reafirmaron su disposición en tal sentido. Cada una de ellas confirmó a la Comisión por separado que estaba dispuesta a hacerlo con

carácter temporal, y a reintegrar los datos a la secretaría de la CNUDMI sin costo una vez que esta confirmara que había obtenido los recursos pertinentes para cumplir el mandato de la Comisión de asumir dicha función.

88. La Comisión encomió vivamente a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y al CIADI por la calidad de la labor de sus respectivas instituciones en materia de arbitraje sobre inversiones, por el respaldo y las contribuciones que habían dedicado a la labor del Grupo de Trabajo y por su apoyo a las funciones de archivo de la transparencia y su disposición a apoyar esa labor en caso de que la secretaría de la CNUDMI no contara con los recursos para asumirla.

89. Tras expresar su agradecimiento por los ofrecimientos de ambas instituciones y por la calidad técnica que llevaban asociada, la Comisión recalcó su esperanza de que cualquiera de las instituciones a la que se pidiera el desempeño temporal de la función de archivo actuara en estrecha colaboración con la secretaría de la CNUDMI y, según fuera necesario, con la otra institución.

90. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y el CIADI procedieron a presentar sus respectivas capacidades técnicas en relación con el desempeño de la función de archivo de la transparencia. Ambas instituciones hicieron referencia a cartas que habían enviado a las delegaciones en las que exponían sus capacidades por escrito de manera más detallada.

Ponencia de las instituciones

91. El Vicesecretario de la Corte Permanente de Arbitraje presentó una ponencia en la que indicó que la Corte era una organización intergubernamental establecida en 1899 de conformidad con la Convención para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales, que fue revisada en 1907⁸. En las dos convenciones constitutivas de la Corte se indicaba que esta debía permanecer disponible en todo momento y para todos los Estados, hubieran o no firmado una de esas convenciones. La cooperación de la Corte Permanente de Arbitraje con la CNUDMI era de larga data. La Corte cumplía la función de designadora de la autoridad nominadora con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976 y su versión revisada en 2010 y había actuado en calidad de tal en más de 500 casos. En los diez últimos años también se había pedido a la Corte que prestara apoyo administrativo en la mayoría de los casos conocidos de arbitraje en materia de inversiones entablados en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, y actualmente se calculaba que administraba las dos terceras partes de los casos conocidos de controversias entre inversionistas y Estados entablados en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. En relación con su actual función de archivo de un número cada vez mayor de arbitrajes públicos, la Corte estaba preparando una base de datos y un motor de búsqueda mejorados para la información sobre los casos que figuraba en su sitio web. Ese proyecto ya estaba totalmente financiado y se podría adaptar a las necesidades concretas que determinara la CNUDMI para el archivo. La Corte indicó que si la propia CNUDMI no pudiera desempeñar la función de archivo de la transparencia conforme al

⁸ Véase Carnegie Endowment for International Peace, *The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907* (Nueva York, Oxford University Press, 1915). El texto de la Convención puede consultarse en inglés en el sitio www.minbuza.nl/en/key-topics/treaties/search-the-treaty-database/1907/10/003316.html (consultado el 1 de agosto de 2013).

Reglamento sobre la Transparencia, estaba dispuesta a asumir dicha función, incluso con carácter provisional.

92. El CIADI resumió su capacidad para desempeñar las funciones de archivo de la transparencia en una carta de fecha 1 de julio de 2013 que se distribuyó a los asistentes, y en la que el Centro indicaba, en líneas generales, que:

a) era miembro del Grupo del Banco Mundial, que era un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas;

b) era una organización de carácter mundial integrada por 149 Estados miembros, la práctica totalidad de los cuales eran miembros de las Naciones Unidas;

c) no pediría a los Estados que financiasen el archivo, ni directamente ni indirectamente por medio de cuotas de miembros (los miembros del CIADI no pagaban cuotas);

d) había administrado aproximadamente el 70% de todos los arbitrajes en materia de inversiones conocidos y había gestionado más casos en materia de inversiones que todas las demás organizaciones juntas;

e) administraba casos en materia de inversiones con arreglo a todo tipo de normas, incluidos los reglamentos de la CNUDMI. También había desempeñado todas las funciones conexas, como las de autoridad nominadora o autoridad de consolidación;

f) era la única institución que disponía de un historial de transparencia, ya que desde 1995 venía publicando detalles procesales, laudos, decisiones y otros documentos relacionados con casos. Desde 2007 ofrecía un servicio de búsqueda textual básica, avanzada y completa de documentos y, desde ese mismo año, desempeñaba efectivamente las tareas propias del archivo;

g) estaba en condiciones de ofrecer a los usuarios un servicio único de búsqueda textual de todos los documentos publicados en relación con los casos que administraba y los casos publicados en su calidad de archivo; ello supondría una ventaja considerable para los usuarios, ya que se centralizarían las dos fuentes principales de jurisprudencia en una sola ubicación de fácil consulta mediante una única búsqueda;

h) era una opción sumamente eficaz en función del costo, ya que no estaba previsto que los Estados aportaran financiación alguna y las partes litigantes deberían abonar una tasa muy reducida una sola vez;

i) podía prepararse para desempeñar las funciones de archivo en el plazo de dos o tres meses, si se le solicitara.

El CIADI también señaló que el alcance del artículo 1 del Reglamento sobre la Transparencia significaba que dicho reglamento podría adoptarse en tratados y por acuerdo entre las partes litigantes, por lo que se aplicaría cada vez con más frecuencia a los casos sometidos al reglamento del CIADI y otros reglamentos.

Deliberaciones

93. Algunas delegaciones señalaron que, en lo referente a su afiliación, no habían ratificado el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre

Estados y Nacionales de Otros Estados⁹, que algunos Estados habían denunciado el Convenio y que, por consiguiente, esos Estados se sentirían más cómodos apoyando la opción del nombramiento temporal de la Corte Permanente de Arbitraje. En respuesta a esto se dijo que, en el contexto del archivo de la transparencia, la pertenencia a una institución u otra carecía de importancia.

94. Algunas delegaciones expresaron la opinión de que el CIADI tenía más experiencia en el ámbito del arbitraje en materia de inversiones y de la transparencia en los procedimientos de arbitraje en materia de inversiones. Se dijo que, habida cuenta en particular del carácter supuestamente temporal de las funciones de archivo de la transparencia que desempeñaría la institución que resultase elegida, sería indispensable que esa institución dispusiera de un máximo de conocimientos institucionales teóricos y prácticos, y que el CIADI era la institución mejor cualificada en ese sentido.

95. Otras delegaciones destacaron también la idoneidad de los servicios técnicos que ofrecía el CIADI, así como la posibilidad de disponer de una función global de búsqueda en textos completos en relación con los procedimientos del Centro y de la CNUDMI.

96. Otras delegaciones consideraban que la función del Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje de designador de la autoridad nominadora conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI establecía un vínculo más natural con la Comisión. También se dijo que la Corte Permanente de Arbitraje administraba una variedad de casos que afectaban a Estados, incluidas controversias entre Estados de conformidad con tratados y controversias surgidas tras la celebración de un contrato entre Estados y particulares, lo que para algunas delegaciones la convertía en la candidata idónea. Algunas delegaciones mencionaron que el importe de la tasa que la Corte Permanente de Arbitraje exigiría a las partes en una controversia era más reducido (publicación gratuita de un máximo de 50 documentos y tasa fija de 750 euros por publicar más de 50 documentos).

97. Tras deliberar, la Comisión acordó por consenso que la Corte Permanente de Arbitraje fuera la institución designada, en caso de necesidad, para desempeñar la función de archivo de la transparencia con carácter temporal hasta que la secretaría de la CNUDMI obtuviera los recursos para hacerlo.

98. Se expresó temor a que la solución temporal de que la Corte actuara de archivo de la transparencia se convirtiera en una solución permanente. La Comisión solicitó, por lo tanto, que en su próximo período de sesiones, en 2014, la Secretaría la informase del estado del establecimiento y funcionamiento del archivo de la transparencia.

Título del Reglamento sobre la Transparencia

99. Se señaló que dando al Reglamento sobre la Transparencia el título de “Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado” quedaría clara a primera vista la aplicabilidad del reglamento en el contexto de los arbitrajes en materia de inversiones y no de los arbitrajes de cuestiones meramente comerciales. Se convino en aceptar esa propuesta.

⁹ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 575, núm. 8359.

Forma de presentación del Reglamento sobre la Transparencia: apéndice o reglamento independiente

100. La Comisión examinó la cuestión de la forma en que había de ponerse a disposición del público el Reglamento sobre la Transparencia, es decir, si el reglamento había de presentarse como un texto independiente o como apéndice de una versión modificada del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. En primer lugar, la Comisión observó que la forma de presentación del Reglamento sobre la Transparencia no afectaría a su ámbito de aplicación conforme al artículo 1. Asimismo observó que en el artículo 1 del Reglamento sobre la Transparencia se preveía la aplicación de este tanto en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (artículo 1, párrafos 1) y 2)) como con arreglo a otros reglamentos de arbitraje o en procedimientos *ad hoc* (artículo 1, párrafo 9)). Además, se indicó que la forma que tendría el reglamento planteaba dos consideraciones de política fundamentales. Por un lado, los usuarios del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI debían ser plenamente informados de la existencia del Reglamento sobre la Transparencia. Por otro, no se debía desalentar el empleo del reglamento por parte de los usuarios comerciales de la versión modificada del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, ni tampoco había que dar a estos la falsa impresión de que el Reglamento de Arbitraje dejaba de ser aplicable a los procesos de arbitraje comercial.

101. Se formuló una propuesta destinada a conciliar esas cuestiones de política. Se sugirió que el Reglamento sobre la Transparencia se publicara junto con la versión modificada del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, pero no como apéndice. Además se sugirió que el Reglamento sobre la Transparencia se publicara como texto independiente.

102. Tras las correspondientes deliberaciones, quedó aprobada la propuesta recogida en el párrafo 101 del presente documento. La Comisión solicitó a la Secretaría que publicara el Reglamento sobre la Transparencia, inclusive en formato electrónico, junto con la versión modificada del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y como texto independiente.

3. Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013)

103. Se recordó que tras el acuerdo de la Comisión relativo al ámbito de aplicación del Reglamento sobre la Transparencia habría que modificar el artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010) a fin de articular una vinculación con el Reglamento sobre la Transparencia (A/CN.9/765, párrs. 79 y 80; y A/CN.9/783, párrs. 28 a 39).

104. La Comisión tomó nota de que el establecimiento de una versión modificada del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, que creara un vínculo con el Reglamento sobre la Transparencia, necesariamente afectaría a las remisiones al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI que figuraran en tratados concertados después de la entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia. Concretamente, se aclaró que una referencia al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI aprobado en 1976, o al revisado en 2010, en un tratado concertado después de la entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia tendría el

efecto de impedir la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia (A/CN.9/783, párr. 31).

Modificación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI

105. La Comisión examinó un nuevo párrafo 4) del artículo 1 que modificaría el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010): “4. En el caso de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas, el presente Reglamento incluye el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia [como apéndice] [con las modificaciones que puedan introducirse ocasionalmente], a reserva de lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia.” (A/CN.9/765, párr. 79; y A/CN.9/783, párr. 29).

106. A raíz del acuerdo (expuesto en los párrafos 101 y 102 del presente documento) de que el Reglamento sobre la Transparencia no se incluiría como apéndice de la versión modificada del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, se convino en consecuencia en suprimir el texto “[como apéndice]” que figuraba entre corchetes.

107. También se examinó el texto del nuevo párrafo 4) del artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI para determinar si debía ser de carácter evolutivo e incluir expresiones como “con las modificaciones que puedan introducirse ocasionalmente” o “en vigor en la fecha de apertura del procedimiento de arbitraje”.

108. En opinión de varias delegaciones incluir un texto de carácter evolutivo podía disuadir a los países de adoptar el Reglamento sobre la Transparencia en tratados futuros. Se señaló que, si bien el texto del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 era de carácter evolutivo (en el artículo 1, párrafo 2)), no lo era el del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976.

109. Tras las correspondientes deliberaciones, se acordó modificar el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010) a fin de incluir un nuevo artículo 1, párrafo 4), redactado como sigue: “4. En el caso de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas, el presente Reglamento incluye el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado, a reserva de lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento sobre la Transparencia”.

Título del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI modificado

110. Se recordó que la modificación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010) daría lugar a una nueva versión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI con la fecha de aprobación de la modificación, y que su fecha de entrada en vigor sería la misma que la de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia (A/CN.9/765, párrs. 33 y 79; y A/CN.9/783, párr. 30).

111. La Comisión examinó el título de esa versión modificada del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Se formuló al respecto la siguiente propuesta: “Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013)”. La propuesta fue aprobada.

B. Examen de instrumentos relativos a la aplicabilidad del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado a la solución de controversias surgidas en el marco de tratados de inversión ya existentes

112. La Comisión recordó que, en su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, había confirmado que la cuestión de la aplicabilidad de la norma jurídica sobre la transparencia a los tratados de inversión concertados antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia guardaba relación con el mandato del Grupo de Trabajo y revestía un gran interés práctico, habida cuenta de los numerosos tratados de inversión ya concertados¹⁰. En ese contexto, la Comisión consideró las opciones para hacer que el Reglamento sobre la Transparencia fuera aplicable a los tratados de inversión existentes, bien mediante una convención, en virtud de la cual los Estados pudieran consentir en aplicar dicho reglamento a los arbitrajes regidos por sus tratados de inversión, o mediante una recomendación en la que se instara a los Estados a dar aplicabilidad al reglamento en el contexto de la solución de controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado. La Comisión tomó nota también de la posibilidad de hacer que el Reglamento sobre la Transparencia fuese aplicable a los tratados de inversión existentes mediante una declaración interpretativa conjunta, con arreglo al artículo 31, párrafo 3) a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, o mediante una enmienda o modificación de un tratado pertinente con arreglo a los artículos 39 a 41 de esa Convención (A/CN.9/784).

Examen de una recomendación

113. Se expresó la opinión de que el mandato del Grupo de Trabajo consistía en estudiar opciones para hacer que el Reglamento sobre la Transparencia fuera aplicable a los tratados de inversión existentes, pero que no determinaba el resultado a favor de una recomendación.

114. La Comisión decidió incluir en la decisión por la que se aprobaría el Reglamento sobre la Transparencia una recomendación en la que se instara a las partes en tratados de inversión a aplicar la norma jurídica sobre la transparencia a los tratados de inversión existentes. El propósito de la recomendación sería poner de relieve la importancia de la transparencia en el contexto de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado. La recomendación dejaría en manos de las partes en los tratados de inversión la decisión sobre los medios de aplicar la norma jurídica sobre la transparencia en el contexto de esos tratados. La Comisión examinó el texto del párrafo 1 del proyecto de recomendación consignado en el párrafo 20 del documento A/CN.9/784.

115. Algunas delegaciones solicitaron que se introdujeran en ese texto expresiones condicionales. La solicitud no recibió respaldo.

¹⁰ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 200.*

116. Tras las correspondientes deliberaciones, se acordó el texto que se indica a continuación, y se solicitó que se incluyera en la decisión de la Comisión por la que se aprobaría el Reglamento sobre la Transparencia:

“Recomienda también que, a reserva de toda disposición del tratado de inversión pertinente que pueda requerir un mayor grado de transparencia, el Reglamento sobre la Transparencia se aplique mediante mecanismos apropiados a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con un tratado de inversión celebrado antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia, en la medida en que dicha aplicación sea compatible con esos tratados de inversión”.

(Véase la decisión en el párrafo 128 del presente documento.)

Examen de la preparación de una convención sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado

117. Varias delegaciones respaldaron la idea de encomendar al Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) la tarea de preparar una convención sobre la transparencia. A modo de aclaración, se indicó que, en caso de que se concertara la convención, esta quedaría abierta a la ratificación por parte de los Estados que desearan adoptar el Reglamento sobre la Transparencia en relación con sus tratados ya en vigor. Se subrayó que ello no implicaría que ningún otro Estado tuviera la obligación de firmar o ratificar esa convención.

118. Se dijo además que un componente esencial de la propuesta de transacción revisada (véase el párrafo 16 del presente documento) era la necesidad, secundaria con relación al Reglamento sobre la Transparencia, de contar con una convención que proporcionara a los Estados un mecanismo simple y eficaz para aplicar el reglamento a los tratados existentes.

119. Esta opinión se justificó con el argumento de que el gran número de tratados existentes, a los que sería aplicable el Reglamento sobre la Transparencia únicamente con arreglo al criterio de la adhesión, hacía que una convención de esa índole fuera esencial para promover y desarrollar la labor de transparencia contenida en el reglamento. Se dijo además que en una etapa siguiente sería lógico elaborar un instrumento multilateral para contraer un compromiso creíble encaminado a lograr la transparencia en el arbitraje en materia de inversiones en el marco de los tratados existentes.

120. Se señaló que los Estados que contaban con un gran número de tratados bilaterales de inversión y que deseaban que el Reglamento sobre la Transparencia se aplicara eficientemente a esos tratados no deberían verse impedidos de hacerlo.

121. En respuesta, se señaló que las normas contenidas en el Reglamento sobre la Transparencia eran nuevas, y que no cabía esperar que todos los Estados estuvieran listos para aplicarlas en ese momento. Se expresó la opinión de que, si bien las delegaciones habían reconocido la importancia de la transparencia, la solución de transacción prevista en el reglamento no era perfecta y una convención tendría el efecto de perturbar el delicado equilibrio alcanzado en el artículo 1 del reglamento.

122. También se expresó la preocupación por que pudiera interpretarse que una convención modificaría la dinámica desde el punto de vista de la negociación de los tratados bilaterales de inversión, o por que se presionara a los Estados para que la adoptaran.

123. A fin de atender a esa preocupación, la Comisión acordó que no había, ni debía hacerse, ningún juicio de valor referido a la decisión que tomara un Estado de adherirse a la convención y que no debía ejercerse presión sobre los Estados para que se adhiriesen a una convención. Se señaló que esa cuestión se podía aclarar, por ejemplo, en el preámbulo de la convención.

124. Para que constara oficialmente, se señaló que el proyecto de texto de una convención presentado a la Comisión en el párrafo 5 del documento A/CN.9/784 era una propuesta de la secretaría que el Grupo de Trabajo aún no había examinado.

125. Tras deliberar, la Comisión convino en prever, además del mandato existente que había confiado al Grupo de Trabajo para examinar las opciones relativas a la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia a los tratados existentes, un mandato específico para preparar una convención a ese respecto. También se tomó nota de las opiniones de las delegaciones que habían manifestado su preocupación en relación con la convención. En consecuencia, la Comisión consideró la posibilidad de encomendar al Grupo de Trabajo un mandato que tuviera en cuenta que el propósito de la convención era dar a los Estados que deseaban que el Reglamento sobre la Transparencia fuera aplicable a sus tratados existentes un mecanismo eficiente con ese fin, sin que se crease ninguna expectativa en el sentido de que otros Estados utilizarían el mecanismo ofrecido por la convención.

126. Algunas delegaciones propusieron que el texto relativo al mandato se redactara como sigue: “La Comisión confía al Grupo de Trabajo el mandato de redactar una convención para facilitar la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia teniendo en cuenta las preocupaciones de algunos Estados respecto de las dificultades que podría plantear la aplicación inmediata del Reglamento sobre la Transparencia a los tratados existentes”. Se dijo que en esa redacción no se declaraba el objetivo de la convención enunciado en el párrafo 125 del presente documento, a saber, dar a los Estados que deseaban que el Reglamento sobre la Transparencia fuera aplicable a sus tratados existentes un mecanismo eficiente con ese fin, y el texto no recibió apoyo.

127. Tras deliberar, la Comisión acordó por consenso confiar al Grupo de Trabajo la tarea de preparar una convención relativa a la aplicación a los tratados existentes del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado, teniendo en cuenta que el propósito de la convención era dar a los Estados que deseaban que el Reglamento sobre la Transparencia fuera aplicable a sus tratados existentes un mecanismo eficiente con ese fin, sin que se crease ninguna expectativa en el sentido de que otros Estados utilizarían el mecanismo ofrecido por la convención.

C. Decisión por la que se aprueba el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013)

128. En su 965ª sesión, celebrada el 11 de julio de 2013, la Comisión adoptó la siguiente decisión:

“La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,

Recordando la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, de 17 diciembre de 1966, por la que se estableció la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional con objeto de promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional en interés de todos los pueblos y, en particular, de los pueblos de los países en desarrollo,

Recordando también las resoluciones de la Asamblea General 31/98, de 15 de diciembre de 1976, y 65/22, de 10 de enero de 2011, en las que se recomienda la utilización del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional¹¹,

Reconociendo el valor del arbitraje como método para resolver las controversias que puedan surgir en el contexto de las relaciones internacionales y la amplia utilización del arbitraje para la solución de controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado,

Reconociendo también la necesidad de que, en las disposiciones sobre la transparencia en la solución de controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado, se tenga en cuenta el interés público al que afectan arbitrajes de esa índole,

Reconociendo además que algunas partes en tratados de inversión han adoptado en determinados tratados elevadas normas de transparencia para la protección de las inversiones o los inversionistas,

Teniendo presente que el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI se aplica ampliamente en la solución de controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado,

Teniendo presente también que, en relación con la modernización del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010), resulta particularmente oportuna la aprobación del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado,

Observando que la preparación del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de

¹¹ Véase el texto del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (1976) en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/31/17)*, cap. V, secc. C. Véase el texto del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010) en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17)*, anexo I.

un Tratado fue objeto de las debidas deliberaciones en la CNUDMI y de que en esas deliberaciones se efectuaron amplias consultas con gobiernos y con organizaciones no gubernamentales internacionales e intergubernamentales interesadas,

Creyendo que el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado contribuiría considerablemente al establecimiento de un marco jurídico armonizado para resolver de forma equitativa y eficiente las controversias internacionales en materia de inversiones,

Reconociendo la necesidad, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado, de que una institución sirva de archivo de información, así como la función esencial que ese archivo de la transparencia desempeñaría en la aplicación del Reglamento,

Recordando la composición universal de las Naciones Unidas y la independencia y neutralidad de su Secretaría,

1. *Aprueba* el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado, que figura en el anexo I del informe de la CNUDMI sobre su 46º período de sesiones (A/68/17), y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013), que figura en el capítulo III, sección A.3, de ese informe;

2. *Solicita* al Secretario General que, por conducto de la secretaría de la CNUDMI, ejerza las funciones de archivo de la transparencia en relación con el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado;

3. *Solicita también* al Secretario General que publique y divulgue ampliamente el texto del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado y del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013), incluso por medios electrónicos, y que los transmita a los gobiernos y a las organizaciones interesadas en la esfera de la solución de controversias;

4. *Recomienda* a todos los Estados que utilicen el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013) para la solución de controversias en materia de inversiones, e invita a las partes en tratados de inversión que incluyan en sus tratados en materia de inversiones el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado a que informen de ello a la Comisión;

5. *Recomienda también* que, a reserva de toda disposición del tratado de inversión pertinente que pueda requerir un mayor grado de transparencia, el Reglamento sobre la Transparencia se aplique mediante mecanismos apropiados a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de

conformidad con un tratado de inversión celebrado antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia, en la medida en que dicha aplicación sea compatible con esos tratados de inversión.”

D. Labor futura

129. La Comisión tomó nota del documento A/CN.9/785 sobre la posible labor futura en la esfera de la solución de controversias comerciales y celebró debates preliminares sobre la labor que podía recomendarse en la esfera del arbitraje internacional habida cuenta del examen que había hecho de esa cuestión en relación con el tema 16 del programa (véanse los párrafos 292 a 332 del presente documento).

130. Se dijo que era necesario, como cuestión prioritaria, actualizar las Notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral (1996)¹². Se convino en que el foro preferido para dicha labor sería el de un grupo de trabajo, a fin de garantizar la preservación de la aceptabilidad universal de esas Notas. Se recomendó que el grupo de trabajo dedicara un único período de sesiones al examen de las Notas y que ese examen tuviera lugar como tema siguiente de la labor futura, después de que se finalizara el proyecto de convención (véase el párrafo 127 del presente documento).

131. Se sugirió que la cuestión de los procedimientos paralelos era cada vez más importante, sobre todo en el ámbito del arbitraje relacionado con las inversiones, y que valdría la pena seguir examinándola. En particular, se dijo que solía suceder que se iniciara un arbitraje en relación con una determinada controversia y que, al mismo tiempo, las partes relacionadas iniciaran procedimientos paralelos, para solicitar, total o parcialmente, la misma reparación. Se dijo, además, que tratar la cuestión de los procedimientos paralelos también se ajustaría a la intención de promover un enfoque del arbitraje armonizado y coherente. Algunas delegaciones observaron que, habida cuenta de la forma en que evolucionaba la cuestión de los procedimientos paralelos, por el momento la creación de un enfoque armonizado podría ser prematura.

132. Otra cuestión planteada fue la de los procedimientos paralelos en el arbitraje comercial, respecto de los cuales la cuestión de prevenir o evitar que se entablaran paralelamente procedimientos en un tribunal de un Estado y procedimientos arbitrales en relación con el mismo asunto tal vez debería abordarse a nivel multilateral. Se hicieron diferentes sugerencias en cuanto a la forma que podría adoptar la labor relativa a los procedimientos paralelos en el arbitraje comercial. Se sugirió que promover una interpretación uniforme del artículo 8 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional¹³ podría ser una solución. Otra opción planteada fue la de formular directrices relativas a esa

¹² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/51/17), cap. II.*

¹³ Véase el texto de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985) en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/40/17), anexo I.* Véase el texto de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985), con las enmiendas aprobadas en 2006, en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/61/17), anexo I* (únicamente los artículos revisados), y publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.08.V.4.

cuestión. También se sugirió que sería prematuro decidir qué forma podría adoptar la labor futura en esa esfera y que cualquier decisión al respecto debería preservar la opción de analizar la cuestión de los procedimientos paralelos en los arbitrajes comerciales en el contexto de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958¹⁴.

133. Se sugirió que se volviera a examinar el tema de la labor futura en un próximo período de sesiones de la Comisión, después que finalizara la labor en curso de elaboración de una convención sobre la transparencia.

E. Preparación de una guía sobre la Convención de Nueva York de 1958

134. En su 28º período de sesiones, celebrado en 1995, la Comisión aprobó un proyecto, realizado conjuntamente con el Comité D (actualmente denominado Comité sobre el Arbitraje) de la Asociación Internacional de Abogados, destinado a la vigilancia de la aplicación en las leyes nacionales de la Convención de Nueva York¹⁵.

135. En su 41º período de sesiones, celebrado en 2008, la Comisión examinó un informe escrito sobre el proyecto, relativo a la aplicación de la Convención de Nueva York por los Estados, su interpretación y aplicación, y los requisitos y procedimientos que los Estados habían establecido para la ejecución de sentencias dictadas en virtud de la Convención, informe que se basaba en las respuestas recibidas de 108 Estados partes en la Convención (A/CN.9/656 y Add.1). En ese período de sesiones, la Comisión acogió con beneplácito las recomendaciones y conclusiones que contenía el informe y señaló que ponían de relieve aspectos sobre los que posiblemente fuera necesario realizar una labor complementaria para mejorar la interpretación uniforme y la aplicación efectiva de la Convención. La Comisión convino en que era preciso realizar trabajos para eliminar o limitar los efectos de la falta de armonía jurídica en ese ámbito. La Comisión fue, en general, de la opinión de que el resultado de ese proyecto debería consistir en la elaboración de una guía sobre la Convención de Nueva York, con miras a promover la interpretación y aplicación uniformes de la Convención, evitando de esa manera la incertidumbre resultante de su aplicación deficiente o parcial y limitando el riesgo de que la práctica de los Estados se apartara del espíritu de la Convención. La Comisión solicitó a la Secretaría que estudiara la viabilidad de preparar una guía de esa índole. Además, en ese período de sesiones la Comisión acordó que, en la medida en que lo permitieran los recursos, las actividades que realizaba la Secretaría en el contexto de su programa de asistencia técnica podían incluir la difusión de información sobre la interpretación judicial de la Convención de Nueva York, que sería de utilidad para complementar otras actividades realizadas en apoyo de la Convención¹⁶.

¹⁴ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 330, núm. 4739.

¹⁵ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo período de sesiones, Suplemento núm. 17* (A/50/17), párrs. 401 a 404.

¹⁶ *Ibid.*, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1), párrs. 355 y 360.

136. La Comisión tomó nota de la resolución 62/65 de la Asamblea General, aprobada el 6 de diciembre de 2007, en que la Asamblea reconocía el valor del arbitraje como método de solución de controversias en las relaciones comerciales internacionales, que contribuía a la armonía de las relaciones comerciales, estimulaba el comercio internacional y el desarrollo y promovía el estado de derecho a nivel nacional e internacional, expresaba su convencimiento de que la Convención de Nueva York había fortalecido el respeto de los compromisos vinculantes, inspirado confianza en el estado de derecho y asegurado un trato justo en la solución de controversias relacionadas con los derechos y obligaciones contractuales, y pedía al Secretario General que intensificara los esfuerzos para promover una adhesión más amplia a la Convención y su interpretación uniforme y aplicación efectiva.

137. La Comisión recordó que, en sus períodos de sesiones 44° y 45°, celebrados en 2011 y 2012, se le había informado de que la Secretaría estaba realizando un proyecto relativo a la preparación de una guía sobre la Convención de Nueva York en estrecha cooperación con el Sr. G. Bermann (Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia) y el Sr. E. Gaillard (École de Droit del Instituto de Ciencias Políticas de París), que habían formado equipos de investigación para trabajar en el proyecto. Se había informado a la Comisión de que el Sr. Gaillard y el Sr. Bermann, junto con sus respectivos equipos de investigación y con el apoyo de la Secretaría, habían creado un sitio web (www.newyorkconvention1958.org) a fin de hacer accesible al público la información reunida para la preparación de la guía sobre la Convención de Nueva York. La finalidad del sitio web era promover la aplicación uniforme y efectiva de la Convención facilitando detalles sobre su interpretación judicial por los Estados partes. Asimismo, se había comunicado a la Comisión que la secretaría de la CNUDMI tenía previsto mantener una relación estrecha entre los casos incluidos en el sistema de recopilación de la jurisprudencia relativa a los textos de la CNUDMI (sistema “CLOUT”) (véanse los párrafos 235 a 240 del presente documento) y los casos que se consignaran en el sitio web dedicado a la preparación de la guía sobre la Convención de Nueva York¹⁷. En su 45° período de sesiones, la Comisión había expresado su reconocimiento por la creación del sitio web y por la labor realizada por la Secretaría y por los expertos y sus equipos de investigación, y había pedido a la Secretaría que prosiguiera sus trabajos para preparar la guía sobre la Convención de Nueva York¹⁸.

138. En su período de sesiones en curso, la Comisión tuvo ante sí un extracto de la guía sobre la Convención de Nueva York para su examen (A/CN.9/786).

139. La Comisión expresó su reconocimiento a la Secretaría y a los expertos y los equipos participantes en el proyecto por la labor realizada para cumplir el mandato que la Asamblea General había encomendado a la Comisión de promover y asegurar la interpretación y aplicación uniformes de los tratados internacionales.

140. Se manifestó preocupación por el hecho de que en una guía se pudiera mostrar preferencia por ciertos puntos de vista con respecto a otros y, por tanto, no se reflejara un consenso internacional sobre la interpretación de la Convención de Nueva York. Así pues, se planteó la cuestión de la forma en que se podría publicar la

¹⁷ *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 252; e *ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 135.

¹⁸ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 136.

guía. En respuesta a ello se señaló que el enfoque adoptado para la preparación de la guía era similar al seguido con otras guías o compendios de la Comisión, como el *Compendio de la CNUDMI sobre jurisprudencia relativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías*¹⁹. Se explicó que existían diversas opciones para la publicación de ese tipo de trabajos. Una de ellas consistía en que la guía se publicara bajo la responsabilidad de la Secretaría, y se dio el ejemplo de la *Guía Jurídica de la CNUDMI sobre Transferencias Electrónicas de Fondos* (1987)²⁰. Se sugirió que la Comisión también podría tomar nota de la guía sobre la Convención de Nueva York sin respaldar su contenido y solicitar a la Secretaría que la publicara. Otra posibilidad sería que la Secretaría distribuyera el texto de la guía, una vez estuviera listo, para recabar las observaciones de los Estados a fin de que la Comisión las examinara en un período de sesiones ulterior. Tras deliberar, la Comisión solicitó a la Secretaría que, con sujeción a la disponibilidad de recursos, le presentara la guía en su siguiente período de sesiones, en 2014, para continuar examinando su situación y la forma en que habría de publicarse.

F. Concursos de arbitraje comercial internacional simulado

1. Concurso de Arbitraje Comercial Internacional Simulado Willem C. Vis

141. Se tomó conocimiento de que la Asociación para la Organización y Promoción del Concurso de Arbitraje Comercial Internacional Simulado Willem C. Vis había organizado el 20º Concurso de Arbitraje Simulado, cuya fase de argumentación oral había tenido lugar en Viena del 22 al 28 de marzo de 2013. Como en años anteriores, el concurso había sido copatrocinado por la Comisión. Las cuestiones jurídicas tratadas por los equipos de estudiantes que habían tomado parte en el concurso se habían basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 1980)²¹. En total habían participado 291 equipos de facultades de derecho de 66 países, y el mejor equipo en la argumentación oral del caso había sido el de la City University of Hong Kong. La fase de argumentación oral del 21º Concurso de Arbitraje Comercial Internacional Simulado Willem C. Vis tendría lugar en Viena del 11 al 17 de abril de 2014.

142. Asimismo se tomó conocimiento de que la Subdivisión de Asia Oriental del Chartered Institute of Arbitrators había organizado, con el patrocinio de la Comisión, el Décimo Concurso de Arbitraje Comercial Internacional Simulado Willem C. Vis (en Oriente). La fase final había tenido lugar en Hong Kong (China) del 11 al 17 de marzo de 2013. En total habían participado en el concurso 93 equipos de 27 jurisdicciones. El equipo ganador en la argumentación oral del caso había sido el de la Universidad de Canberra. El 11º Concurso de Arbitraje Comercial Internacional Simulado Willem C. Vis (en Oriente) se celebraría en Hong Kong (China) del 31 de marzo al 6 de abril de 2014.

¹⁹ Puede consultarse en www.uncitral.org/uncitral/es/case_law/digests.html (consultado en español el 16 de septiembre de 2013).

²⁰ Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.87.V.9.

²¹ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1489, núm. 25567.

2. Concurso de Arbitraje Comercial Simulado de Madrid 2013

143. Se tomó conocimiento de que la Universidad Carlos III de Madrid había organizado en esa ciudad el Quinto Concurso de Arbitraje Comercial Internacional Simulado, del 15 al 20 de abril de 2013, que también había sido copatrocinado por la Comisión. Las cuestiones jurídicas debatidas se habían referido a una venta internacional de acciones a la que eran aplicables la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa y los Principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) sobre los contratos comerciales internacionales²², así como la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, la Convención de Nueva York y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010). La Corte de Arbitraje de Madrid había actuado como autoridad nominadora. En el Concurso de Madrid, celebrado en español, habían participado en total 23 equipos de facultades de derecho o programas de posgrado de ocho países. El mejor equipo en la argumentación oral había sido el de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), que había ganado la final contra la Universidad Pontificia Católica del Perú. El sexto Concurso de Madrid se celebraría del 21 al 25 de abril de 2014.

IV. Examen de cuestiones relacionadas con las garantías reales

A. Finalización y aprobación de la Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales

1. Introducción

144. En su actual período de sesiones, la Comisión tuvo ante sí: a) una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.54 y Add.1 a Add.4), que contenía un comentario; b) una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía de la CNUDMI sobre la creación de un registro de garantías reales” (A/CN.9/781 y Add.1 y Add.2, que contenía, en las respectivas adiciones, todas las modificaciones del comentario, la terminología y las recomendaciones y los ejemplos de formularios de registro del proyecto de guía del registro convenidos por el Grupo de Trabajo en su 23º período de sesiones (A/CN.9/767, párr. 15); y c) los informes del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre sus períodos de sesiones 22º y 23º (A/CN.9/764 y A/CN.9/767, respectivamente).

145. Al principio, la Comisión acordó que debía encomendarse a la Secretaría que efectuara las modificaciones necesarias para aplicar las decisiones adoptadas por la Comisión en el período de sesiones en curso, garantizar la coherencia de la terminología empleada y evitar las duplicaciones.

²² Puede consultarse en www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf (consultado en español el 16 de septiembre de 2013).

2. Examen del proyecto de guía sobre el registro

Prefacio (A/CN.9/WG.VI/WP.54 y A/CN.9/781, párrafos 1 y 2)

146. La Comisión aprobó el prefacio del proyecto de guía sobre el registro sin modificaciones, en el entendimiento de que se actualizaría para que quedaran reflejadas las decisiones que adoptase la Comisión en su período de sesiones en curso.

Introducción (A/CN.9/WG.VI/WP.54, A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrafos 1 a 23, A/CN.9/781, párrafos 3 a 24, y A/CN.9/781/Add.1, terminología)

147. Con respecto al párrafo 4, apartado g), del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54, la Comisión convino en que la referencia a las Normas y Procedimientos para el Registro Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional debía actualizarse a fin de que remitiera a la quinta edición, publicada en 2013.

148. Con respecto al término “dirección”, la Comisión convino en que debía revisarse de modo que hiciera referencia a: a) una dirección física, que podría ser bien una dirección postal o bien un apartado postal, y b) una dirección electrónica. La Comisión acordó también que el comentario debía ofrecer ejemplos de otras direcciones que también pudieran resultar eficaces para comunicar información y explicar que los Estados promulgantes deberían designar los formularios de registro de tal modo que los autores de las inscripciones pudieran escoger entre los tipos de dirección mencionados.

149. Con respecto al término “otorgante”, la Comisión estuvo de acuerdo en que debía revisarse de modo que hiciera referencia a la persona identificada “en el espacio previsto” de la notificación como otorgante (en cuanto al significado del término “otorgante”, véanse también los párrafos 169 y 170 del presente documento).

150. Con respecto al término “autor de la inscripción”, la Comisión convino en que debía revisarse de modo que hiciera referencia a la “persona que presenta el formulario de notificación prescrito al registro”. La Comisión convino además en que en el comentario se debía aclarar que los servicios de mensajería o servicios postales de otra índole que empleara el autor de la inscripción para transmitir una notificación en papel no tendrían la consideración de autor de la inscripción.

151. Con respecto al término “reglamento”, la Comisión convino en que debía revisarse de modo que hiciera referencia al conjunto de reglas que “apruebe” (en lugar de “aplique”) el Estado promulgante con respecto al registro, ya que la aprobación sería anterior a la aplicación.

152. Con respecto al término “acreedor garantizado”, la Comisión estuvo de acuerdo en que se revisara a fin de que hiciera referencia a la persona identificada en el “espacio previsto” de la notificación como acreedor garantizado (en cuanto al significado de la expresión “acreedor garantizado”, véanse también los párrafos 169 y 170 del presente documento).

153. Con respecto al párrafo 23 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54, la Comisión convino en que las palabras del apartado c) de la segunda oración “ha de indicar la intención del otorgante de crear una garantía real” debían suprimirse, dado que la cuestión ya estaba comprendida en el apartado b) de esa oración.

154. Con respecto al párrafo 28 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54, la Comisión acordó que la segunda oración debía revisarse de modo que dijera que la inscripción de una notificación en el registro general de las garantías reales era el método general para lograr la oponibilidad a terceros, excepto en lo que respecta a las garantías reales sobre un derecho al cobro del producto de una promesa independiente (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*²³, recomendaciones 32 y 50).

155. En lo que respecta a los párrafos 18 a 20 de A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, la Comisión convino en que debían revisarse a fin de aclarar que solo sería necesario coordinar las inscripciones registrales si el régimen de las operaciones garantizadas excluía determinados tipos de activos y existía un registro especializado con respecto a esos tipos de activos.

156. Con sujeción a esos cambios, la Comisión aprobó la introducción del proyecto de guía sobre el registro.

**Capítulo I. Establecimiento y funciones del registro de garantías reales
(A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrs. 34 a 49, A/CN.9/781, párrs. 26 a 31,
y A/CN.9/781/Add.1, recomendaciones 1 a 3)**

157. La Comisión aprobó el capítulo I (Establecimiento y funciones del registro de garantías reales) sin modificaciones.

**Capítulo II. Acceso a los servicios del registro (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1,
párrs. 50 a 65, A/CN.9/781, párrs. 26 a 31 y A/CN.9/781/Add.1,
recomendaciones 4 a 10)**

158. Con respecto a las recomendaciones 4 a 10, la Comisión convino en lo siguiente:

a) el apartado a) i) de la recomendación 6 debía revisarse de modo que hiciera referencia al formulario “aplicable” que prescribía el registro;

b) las palabras “Salvo lo dispuesto en las recomendaciones 8, apartado a), y 10, apartado a)” debían añadirse al principio de la recomendación 7, apartado c); y

c) el apartado a) de la recomendación 8 debía revisarse de modo que hiciera referencia a “información” no incorporada en “cada” espacio previsto.

159. Con sujeción a esas modificaciones, la Comisión aprobó el capítulo II (Acceso a los servicios del registro).

**Capítulo III. Registro (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 1 a 49, A/CN.9/781,
párrs. 32 a 40, y A/CN.9/781/Add.1, recomendaciones 11 a 22)**

160. Con respecto al párrafo 44 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, la Comisión acordó que debía explicarse también que todo anexo de una notificación formaba parte de dicha notificación y, por tanto, debía eliminarse también cuando la información consignada en esa notificación se eliminase del fichero del registro accesible al público.

²³ Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.09.V.12.

161. Con respecto a la recomendación 12, la Comisión convino en que debían añadirse al principio de esta las palabras “a los fines de las recomendaciones 16, 18, 30, 32 y 34,” a fin de aclarar su alcance, y que debía colocarse justo delante de la recomendación 16.

162. Con respecto a la recomendación 13, la Comisión examinó varias propuestas acerca de cómo llevar a la práctica el objetivo de la variante C de fijar un límite máximo al plazo de vigencia de la inscripción registral de una notificación. En una de las propuestas se indicaba que, en caso de prórroga, el nuevo plazo podría comenzar cuando se inscribiera la notificación de modificación con el plazo máximo que le fuese aplicable. Como resultado, si el plazo máximo fuera, por ejemplo, de 15 años y el autor de la inscripción decidiera consignar siete años en la notificación inicial, el autor de la inscripción podría consignar 15 años en cada notificación de modificación. En apoyo de esa propuesta se dijo que ese planteamiento sería similar al que se adoptaba en la variante A, según el cual cada notificación de modificación sería válida durante el plazo que especificase la ley. Se señaló también que ese planteamiento aportaría la flexibilidad necesaria para tener en cuenta las necesidades de las partes en acuerdos de garantía a largo plazo. En otra propuesta se contemplaba que el nuevo plazo comenzase al expirar el plazo en curso, siempre que todas las notificaciones juntas no excedieran del plazo máximo. Se dijo que, como resultado, en el ejemplo que se menciona más arriba el autor de la notificación solo podría consignar ocho años en la notificación de modificación. En apoyo de esa propuesta se señaló que, con ese planteamiento, se aplicaría cabalmente la intención que inspiraba la variante C de fijar un plazo máximo y, por tanto, se establecía una diferencia real entre la variante B (en la que no se contemplaba un plazo máximo) y la variante C. Hubo aún otra propuesta en el sentido de que el nuevo plazo podría comenzar cuando se inscribiese la notificación de modificación y el plazo máximo se aplicaría a una única notificación de modificación, con lo que, en el ejemplo que se menciona más arriba, en el registro podría consignarse un plazo de 15 años únicamente en la primera notificación de modificación.

163. Tras deliberar, la Comisión convino en que la recomendación 13 se revisara de modo que dijera lo siguiente:

“El reglamento debería disponer que:

Variante A

a) Toda inscripción de una notificación inicial permanezca vigente eficacia durante [un plazo breve, por ejemplo, de cinco años, que especifique la ley del Estado promulgante];

b) El plazo de vigencia de la inscripción se pueda prorrogar antes de su expiración durante [un plazo breve, por ejemplo, de seis meses, que especifique la ley del Estado promulgante]; y

c) La inscripción de una notificación de modificación por la que se prorrogue el plazo de vigencia prorrogue dicho plazo durante [el plazo especificado en el apartado a)] a partir de la fecha en que expire el plazo en curso.

Variante B

a) La inscripción de una notificación inicial permanezca vigente durante el plazo indicado por el autor de la inscripción en el espacio previsto en la notificación;

b) El plazo de vigencia de la inscripción pueda prorrogarse en cualquier momento antes de que expire mediante la inscripción de una notificación de modificación que indique en el espacio previsto un nuevo plazo de vigencia; y

c) La inscripción de una notificación de modificación por la que se prorrogue el plazo de vigencia prorrogue dicho plazo durante el tiempo especificado por el autor de la inscripción en la notificación de modificación a partir de la fecha en que expire el plazo en curso.

Variante C

a) La inscripción registral de una notificación inicial permanezca vigente durante el plazo indicado por el autor de la inscripción en el espacio previsto de dicha notificación, que no será superior a [un plazo prolongado, por ejemplo, de 20 años, que especifique la ley del Estado promulgante];

b) El plazo de vigencia de la inscripción se pueda prorrogar antes de su expiración durante [un plazo breve, por ejemplo, de seis meses, que especifique la ley del Estado promulgante] mediante la inscripción de una notificación de modificación en la que se indique en el espacio previsto un nuevo plazo de vigencia que no sea superior a [el plazo máximo especificado en el apartado a)]; y

c) La inscripción de una notificación de modificación por la que se prorrogue el plazo de vigencia prorrogue dicho plazo durante el tiempo especificado por el autor de la inscripción en la notificación de modificación a partir de la fecha en que expire el plazo en curso.”

164. Con respecto a la recomendación 14, la Comisión acordó que en ella debía hacerse referencia a “una” garantía real y “un” acuerdo de garantía.

165. Con respecto a la recomendación 18, la Comisión acordó que en el apartado b) ii) debía: a) hacerse referencia también a las notificaciones de cancelación; b) hacerse referencia a “una” dirección actual del otorgante, por cuanto este podría tener más de una dirección; y c) aclararse que si el acreedor garantizado no conociera la dirección del otorgante, tendría derecho a enviar la copia de la notificación a la última dirección “conocida” del otorgante o a la dirección del otorgante que estuviese “razonablemente disponible”. La Comisión acordó también que en el comentario debía explicarse que la modificación se refería a la dirección pertinente del otorgante (por ejemplo, la dirección del otorgante consignada en el fichero del registro), ya que de otra forma el acreedor garantizado podría correr el riesgo de enviar la copia a una dirección errónea o podría abusar de ese derecho enviando la copia a una dirección irrelevante para la operación que daba lugar a la garantía real objeto de la notificación.

166. Con respecto a la recomendación 22, la Comisión convino en que debía revisarse a fin de aclarar que la información contenida en la notificación debía expresarse en el conjunto de caracteres determinado y hecho público por el registro.

167. Con sujeción a los cambios mencionados más arriba, la Comisión aprobó el capítulo III (Registro) del proyecto de guía sobre el registro.

Capítulo IV. Inscripción de notificaciones iniciales (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 50 a 71, A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3, párrs. 1 a 35, A/CN.9/781, párrs. 41 a 58, y A/CN.9/781/Add.1, recomendaciones 23 a 29)

168. Con respecto al párrafo 55 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, la Comisión acordó que debía suprimirse la referencia que figuraba en la segunda oración al formulario de solicitud de consulta, ya que no era necesario que en una solicitud de consulta se consignara la dirección del otorgante.

169. Con respecto a algunas recomendaciones, se expresó la opinión de que los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” no se referían a las personas identificadas en la notificación como otorgante y acreedor garantizado (como se explicaba en la terminología), sino al otorgante y al acreedor garantizado reales. Se formularon varias propuestas al respecto. En una de ellas se indicaba que debían utilizarse términos diferentes en función del contexto (por ejemplo, “otorgante” y “otorgante según el registro”). En otra propuesta se indicaba que en la terminología debía aclararse que, en función del contexto, por otorgante (o acreedor garantizado) se entendía el otorgante real (o el acreedor garantizado real) o el otorgante (o acreedor asegurado) identificado o que hubiera de identificarse en la notificación como otorgante (o acreedor garantizado). En una tercera propuesta se indicaba que podía incluirse una aclaración en el comentario, junto con otra aclaración acerca del contexto en que esos términos tuvieran uno u otro significado.

170. Tras deliberar, la Comisión convino en que: a) debía suprimirse la explicación de los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” que figuraba en la sección de terminología del proyecto de guía sobre el registro; b) en el comentario relativo a la sección de terminología se debería explicar que esos términos tenían, por lo general, el mismo significado que en la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, excepto en determinados casos en los que, según el contexto, se referían a la persona identificada en la notificación; c) la expresión “acreedor garantizado”, que figuraba en la recomendación 3, apartado g), y en las recomendaciones 18, 19 y 31, debía sustituirse por la frase “la persona identificada en la notificación como el acreedor garantizado”; d) el término “otorgante”, que figuraba en la recomendación 18, debía sustituirse por la frase “la persona identificada en la notificación como otorgante”; e) en el comentario de la recomendación 19, en su forma revisada, se debía aclarar que la persona identificada en la notificación como el acreedor garantizado sería la persona autorizada para modificar la información consignada en una notificación inscrita; y f) en el comentario de la recomendación 33 se debía aclarar que esa recomendación se refería a la obligación del acreedor garantizado propiamente dicho.

171. En cuanto a la recomendación 23, se convino en que deberían suprimirse las palabras que figuraban al final del apartado b) (“en la misma notificación o en notificaciones diferentes”) y que en el comentario se podría explicar que, en caso de que hubiera múltiples otorgantes o acreedores garantizados, el autor de la inscripción decidiría si inscribir la información exigida en la misma notificación o en notificaciones diferentes.

172. En cuanto a la recomendación 24, la Comisión convino en que los apartados b) a e) eran demasiado prescriptivos y que, de todos modos, cada Estado promulgante tendría que revisarlos en función de sus convenciones en materia de nombres. La Comisión decidió, por lo tanto, que los ejemplos de los apartados b) a e) deberían incluirse en el comentario y, en su lugar, la recomendación 24 debería incluir texto del siguiente tenor: “b) [el Estado promulgante deberá especificar los diversos componentes del nombre del otorgante y el espacio previsto para cada componente]”; y “c) [el Estado promulgante deberá especificar qué documentos oficiales servirán de base para determinar el nombre del otorgante, así como el orden jerárquico de esos documentos oficiales]”. Además, la Comisión convino en añadir un apartado nuevo que dijera: “d) [el Estado promulgante deberá especificar el modo en que se deberá determinar el nombre del otorgante en caso de que se produzca un cambio de nombre tras la expedición de un documento oficial]”.

173. Respecto a la recomendación 25, la Comisión convino en que, por motivos de coherencia con la recomendación 24, debía revisarse para incluir dos apartados del siguiente tenor: “a) El identificador del otorgante es su nombre”; y “b) El nombre del otorgante es el que se indique en [el documento, ...] más reciente por el que se constituya la persona jurídica”.

174. En cuanto a la recomendación 26, la Comisión convino en que, para mantener la coherencia con la recomendación 24, debía revisarse por un texto del siguiente tenor: “[El Estado promulgante deberá especificar cuál será el identificador del otorgante en casos especiales, por ejemplo en el caso de una persona que sea objeto de un procedimiento de insolvencia, o un fideicomisario o un representante de un patrimonio]”. También se acordó que los ejemplos presentados en la recomendación 26 debían incluirse en el comentario con las modificaciones correspondientes (véase la nota a la Comisión que figura tras la recomendación 26 contenida en el documento A/CN.9/781/Add.1).

175. Con respecto a la recomendación 28, la Comisión convino en que las palabras “Si la ley no dispone otra cosa”, que figuraban al principio de los apartados b) y c), debían suprimirse, porque inadvertidamente podían dar la impresión de que tenían por objeto introducir una excepción al principio de legalidad que figuraba en el apartado a) (véase la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 14, apartado d), y recomendación 63).

176. En relación con la recomendación 29, apartado a), se acordó que, en la versión inglesa, a fin de evitar la tautología expresada en la frase “an amendment notice that amends”, esta debería decir “an amendment notice that changes”.

177. Con sujeción a los cambios mencionados, la Comisión aprobó el capítulo IV (Inscripción de notificaciones iniciales).

Capítulo V. Inscripción de notificaciones de modificación y de cancelación
(A/CN.9/WG.VI/ WP.54/Add.4, párrs. 1 a 41, A/CN.9/781, párrs. 59 a 69,
y A/CN.9/781/Add.1, recomendaciones 30 a 33)

178. En cuanto a la recomendación 31, la Comisión convino en que tanto la variante A como la B se debían revisar de modo que indicaran que el acreedor garantizado mencionado en múltiples notificaciones inscritas pudiera modificar, o pedir al registro que modificara “su información” (y no la información de otros acreedores garantizados mencionados en esas notificaciones).

179. Respecto a la recomendación 32, si bien se definía el número de inscripción como un número único que el registro asignaba a una notificación inicial, a fin de mantener la coherencia con la recomendación 30, apartado a), inciso i), la Comisión acordó que se debía hacer referencia al número de inscripción de la notificación “inicial”.

180. En relación con la recomendación 33, la Comisión convino en que en ella debía hacerse referencia a la obligación del acreedor garantizado de “inscribir” (y no “presentar”) una notificación de modificación o de cancelación. La Comisión acordó también que en el comentario debía explicarse que esa formulación tenía por objeto asegurar que no se pudiera considerar que un acreedor garantizado hubiera cumplido con su obligación simplemente por haber presentado una notificación, sin haberse asegurado de que la notificación se inscribiría realmente y no sería rechazada por alguna de las razones enunciadas en la recomendación 8.

181. Con sujeción a los cambios mencionados, la Comisión aprobó el capítulo V (Inscripción de notificaciones de modificación y de cancelación).

Capítulo VI. Criterios y resultados de la consulta (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 42 a 51, A/CN.9/781, párrs. 70 a 71, y A/CN.9/781/Add.1, recomendaciones 34 y 35)

182. Con respecto a los párrafos 46 a 48 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, la Comisión convino en que la recuperación de la información debía explicarse haciendo referencia a una búsqueda hecha por el registro de conformidad con su lógica de búsqueda. La Comisión convino también en que debía suprimirse la referencia a “lógica de búsqueda”, dado que se trataba de un término técnico que tal vez no se utilizase en todos los Estados y, en todo caso, su contenido (a saber, la manera en que se organizaba y recuperaba la información) sería parte integrante de todo sistema de registro. En consecuencia, la Comisión acordó que en la recomendación 35, apartado b), debía suprimirse la referencia a “lógica de búsqueda”. Con sujeción a esos cambios, la Comisión aprobó el capítulo VI (Criterios y resultados de la consulta).

Capítulo VII. Tasas de inscripción y de consulta (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 52 a 58, A/CN.9/781, párr. 72, y A/CN.9/781/Add.1, recomendación 36)

183. La Comisión aprobó el capítulo VII (Tasas de inscripción y de consulta) sin cambios.

Anexo II. Ejemplos de formularios de registro (A/CN.9/781/Add.2)

184. La Comisión se ocupó seguidamente de los ejemplos de formularios de registro, contenidos en el anexo II del proyecto de guía sobre el registro. Con respecto al formulario I (Notificación inicial), la Comisión acordó lo siguiente: a) debían suprimirse las casillas delante de “Persona física” y “Persona jurídica” en las secciones A y B (debía hacerse el mismo cambio en el formulario II, secciones A a F, en el formulario IV, secciones C y D, y en el formulario VI, sección A); b) la referencia al “Apartado postal (si corresponde)” en las secciones A y B debía revisarse para que dijera “Calle o apartado postal (si corresponde)” (debía hacerse el mismo cambio en el formulario II, secciones A, C, D y F, en el formulario IV, secciones A y D, y en el formulario V, sección A); c) las referencias a “Dirección

electrónica o de otro tipo (si corresponde)” en las secciones A y B debían modificarse para que dijeran “Dirección electrónica (si corresponde)” (debía hacerse el mismo cambio en el formulario II, secciones A, C, D y F, en el formulario IV, secciones A y D, y en el formulario V, sección A); d) debía suprimirse el recuadro “Información adicional sobre el otorgante” bajo “Persona jurídica” en la sección A (debía hacerse el mismo cambio en el formulario II, secciones A y C y en el formulario IV, sección D); e) el recuadro sobre casos especiales de otorgantes en la sección A debía colocarse entre corchetes, con una nota de pie de página que hiciera referencia al comentario pertinente (debía hacerse el mismo cambio en el formulario II, secciones A y C, y en el formulario IV, sección D); f) debían suprimirse las secciones A.2 y B.2 e insertarse una nota que indicara que los formularios debían diseñarse de manera que se adaptaran a los casos en que hubiese múltiples otorgantes o acreedores garantizados; y g) debía revisarse la sección D para que reflejara las opciones A a C de la recomendación 13.

185. Por lo que respecta al formulario II (Notificación de modificación), la Comisión decidió lo siguiente: a) en el segundo recuadro, “Núm. de inscripción de la notificación inicial” debía revisarse para que dijera “Núm. de inscripción de la notificación inicial a que se refiere la modificación” (el mismo cambio debía introducirse en el segundo recuadro del formulario IV y en el formulario VIII, sección B.2); y b) la sección J debía decir “J. Prórroga del plazo de vigencia de la inscripción” y debía revisarse para que se reflejaran en ella las variantes A a C de la recomendación 13.

186. Con respecto al formulario III (Notificación de cancelación), la Comisión convino en que había que revisar el texto del segundo recuadro, “Núm. de inscripción de la notificación inicial que ha de cancelarse”, para que dijera “Núm. de inscripción de la notificación inicial a que se refiere la cancelación” (el mismo cambio debía introducirse en el segundo recuadro del formulario V y en el formulario VIII, sección B.3).

187. Por lo que se refiere al formulario IV (Notificación de modificación con arreglo a una orden judicial o administrativa), la Comisión decidió que se suprimiera toda la sección G (Prórroga o reducción del plazo de vigencia de la inscripción). En cuanto al formulario VI (Formulario de solicitud de consulta), la Comisión convino en que era necesaria una sección aparte para que los investigadores que presentaran una solicitud de consulta de documentos pudieran indicar el nombre de la persona y la dirección a que se debía enviar el resultado de la consulta.

188. En cuanto al formulario VII (Resultados de la consulta), la Comisión acordó que en la nota de pie de página debería reiterarse la recomendación 35 de que en el resultado de la consulta se consignara toda la información de cada notificación inscrita que coincidiera con el criterio de consulta especificado, sin necesidad de realizar una consulta adicional; la presentación de esa información podía variar en función del sistema de registro.

189. Con respecto al formulario VIII (Rechazo de una solicitud de inscripción o de consulta), la Comisión decidió que: a) los motivos del rechazo de una solicitud debían indicarse de forma más concreta en la sección B, y había que incluir casillas independientes para la dirección del otorgante y el acreedor garantizado; y b) debía

suprimirse la palabra “pertinente” en la sección B.2, y debían incluirse casillas independientes para indicar la adición, supresión o modificación de información.

190. Con sujeción a los cambios mencionados, la Comisión aprobó el anexo II (Ejemplos de formularios de registro).

3. Aprobación de la Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales

191. En su 970ª sesión, celebrada el 16 de julio de 2013, la Comisión adoptó la siguiente decisión:

“La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,

Recordando la resolución 63/121 de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 2008, en que la Asamblea recomendó que todos los Estados tomaran debidamente en consideración la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*²⁴ al revisar o aprobar legislación relativa a las operaciones garantizadas,

Reconociendo que es probable que un régimen eficiente de operaciones garantizadas, con un registro de garantías reales de acceso público como el que se recomienda en la Guía de las Operaciones Garantizadas, aumente el acceso a un crédito garantizado asequible y, de ese modo, promueva el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, el estado de derecho y la inclusión financiera y ayude a combatir la pobreza,

Observando con satisfacción que la Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales es coherente con la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, de la que constituye un complemento útil, y que, juntas, las dos guías ofrecerán una orientación completa a los Estados con respecto a las cuestiones jurídicas y prácticas que deben resolverse al establecer un régimen moderno de operaciones garantizadas,

Observando también que la reforma del régimen de las operaciones garantizadas no podría llevarse a cabo eficazmente sin el establecimiento de un registro de garantías reales eficiente y de acceso público, en el que pueda consignarse información acerca de la posible existencia de garantías reales sobre los bienes muebles, y que los Estados necesitan con urgencia orientación respecto del establecimiento y funcionamiento de tales registros,

Observando además que la armonización de los registros nacionales de garantías reales sobre la base de la Guía sobre un Registro aumentará probablemente la disponibilidad de crédito transfronterizo y, de ese modo, facilitará el desarrollo del comercio internacional, lo cual, si se logra de manera igualitaria y en beneficio de todos los Estados, es un elemento importante para promover las relaciones de amistad entre los Estados,

Expresando su reconocimiento a las organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales que trabajan en la reforma del

²⁴ Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.09.V.12.

régimen de las operaciones garantizadas por su participación en la elaboración de la Guía sobre un Registro y su apoyo a ese proceso,

Expresando su reconocimiento también a los participantes en el Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales), así como a la Secretaría, por su contribución a la elaboración de la Guía sobre un Registro,

1. *Aprueba* la Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales, consistente en el texto que figura en los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.54, A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1 a Add.4, A/CN.9/781 y A/CN.9/781/Add.1 y Add.2, con las enmiendas aprobadas por la Comisión en su 46° período de sesiones, y autoriza a la Secretaría a editar y finalizar el texto de la Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales con arreglo a lo decidido en las deliberaciones de la Comisión en ese período de sesiones;

2. *Solicita* al Secretario General que publique la Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales, también por medios electrónicos, y que le dé amplia difusión entre los gobiernos y los órganos interesados;

3. *Recomienda* que todos los Estados tomen debidamente en consideración la Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales al revisar la legislación, la reglamentación administrativa o las directrices pertinentes, y la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*²⁵ al revisar o aprobar legislación relativa a las operaciones garantizadas, e invita a los Estados que hayan utilizado las guías a que informen al respecto a la Comisión; y

4. *Recomienda también* que todos los Estados sigan considerando la posibilidad de adherirse a la Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de créditos en el comercio internacional²⁶, cuyos principios se reflejan asimismo en la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* y cuyo anexo facultativo se refiere a la inscripción registral de las cesiones.”

B. Informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo VI y labor futura

192. Recordando su decisión de confiar al Grupo de Trabajo la preparación de una ley modelo sobre las operaciones garantizadas sencilla, breve y concisa, que se basara en las recomendaciones de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas y se ajustara a todos los textos preparados por la CNUDMI en materia de operaciones garantizadas, la Comisión observó que, en su 23° período de sesiones, el Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) había mantenido un intercambio general de opiniones basándose en una nota preparada por la Secretaría titulada “Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas” (A/CN.9/WG.VI/WP.55 y Add.1 a Add. 4). La Comisión observó también que la Secretaría estaba preparando una versión

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Resolución 56/81 de la Asamblea General, anexo.

revisada del proyecto de ley modelo que daría aplicación al mandato que la Comisión había confiado al Grupo de Trabajo y facilitaría las operaciones de financiación comercial.

193. Se acordó que la preparación del proyecto de ley modelo era un proyecto extremadamente importante para completar la labor de la Comisión en la esfera de las garantías reales e impartir a los Estados una orientación urgentemente requerida acerca del modo de dar aplicación a las recomendaciones de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas. También se acordó que, en vista de la importancia que revestía una legislación moderna sobre las operaciones garantizadas para la oferta y el costo del crédito, y dada la importancia del crédito para el desarrollo económico, esa orientación era sumamente importante y urgente para todos los Estados en un momento de crisis económica, y en particular para los Estados con economías en desarrollo y economías en transición. Además, se señaló que en el ámbito del proyecto de ley modelo se deberían incluir todos los bienes de valor económico.

194. Tras deliberar al respecto, y con sujeción a ulteriores deliberaciones sobre las prioridades que estableciera respecto a la labor prevista y posible labor futura (véanse los párrafos 292 a 332 del presente documento), la Comisión confirmó su decisión de que el Grupo de Trabajo VI preparara una ley modelo sobre las operaciones garantizadas sencilla, breve y concisa, basada en las recomendaciones de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas y que se ajustara a todos los textos preparados por la CNUDMI en materia de operaciones garantizadas.

V. Examen de cuestiones relacionadas con el régimen de la insolvencia

A. Finalización y aprobación de las revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza

195. La Comisión recordó su decisión de encomendar al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) el mandato de desarrollar varios temas, el primero de ellos relacionado con la propuesta de los Estados Unidos descrita en el documento A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.1, párrafo 8, de dar orientación sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza²⁷ relacionados con el centro de los principales intereses y, posiblemente, elaborar una ley modelo o disposiciones modelo sobre el régimen de la insolvencia en que se regularan determinadas cuestiones del derecho internacional de la insolvencia, como las relativas a la jurisdicción, el acceso a los tribunales extranjeros y el reconocimiento de los procedimientos extranjeros, de un modo que no impidiera preparar una convención²⁸.

196. Con respecto a la primera parte de ese mandato, la Comisión tuvo ante sí el texto de las revisiones propuestas de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza (véase A/CN.9/WG.V/WP.112)

²⁷ Resolución 52/158 de la Asamblea General, anexo.

²⁸ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), párr. 259.*

y otras revisiones acordadas por el Grupo de Trabajo en su 43º período de sesiones (véase A/CN.9/766).

197. Habiendo examinado el texto, la Comisión aprobó las siguientes revisiones adicionales:

a) Reinserción de los párrafos 14 a 17 de la versión publicada de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza²⁹ a continuación del párrafo 13, bajo el epígrafe “B. Origen de la Ley Modelo”;

b) Inserción de una remisión en los párrafos 123F y 123G a fin de aclarar que la fecha que el tribunal debía tomar como referencia para examinar esos factores era la fecha especificada en los párrafos 128A a 128D;

c) Sustitución de las palabras “La Ley Modelo” al principio del párrafo 166 por las palabras “El Artículo 23, párrafo 1”.

198. En su 973ª sesión, celebrada el 18 de julio de 2013, la Comisión aprobó la siguiente decisión:

“La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,

Observando que en alrededor de 20 Estados se ha promulgado legislación basada en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza³⁰,

Observando también el aumento generalizado de los procedimientos de insolvencia transfronteriza y, por consiguiente, las ocasiones cada vez más numerosas de utilizar y aplicar la Ley Modelo en ellos, así como de establecer jurisprudencia internacional en que se interpreten sus disposiciones,

Observando además que con frecuencia los tribunales se remiten a la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo³¹, a fin de hallar orientación sobre los antecedentes de la redacción y la interpretación de sus disposiciones,

Reconociendo que la jurisprudencia resultante de su aplicación en la práctica ha creado alguna incertidumbre con respecto a la interpretación de algunas disposiciones de la Ley Modelo,

Convencida de que al interpretar esas disposiciones sería conveniente tener en cuenta el origen internacional de la Ley Modelo y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación,

Convencida también de la conveniencia de impartir nuevas orientaciones, mediante la revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo con respecto a la interpretación y aplicación de determinados aspectos de su texto, a fin de facilitar esa interpretación uniforme,

²⁹ A/CN.9/442, anexo.

³⁰ Resolución 52/158 de la Asamblea General, anexo.

³¹ A/CN.9/442, anexo.

Agradeciendo el apoyo y la participación de organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales interesadas en la reforma del régimen de la insolvencia en la revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo,

Expresando su reconocimiento al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) por su labor de revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo,

1. *Aprueba* la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza, que figura en el documento A/CN.9/WG.V/WP.112, con las revisiones introducidas por el Grupo de Trabajo en su 43º período de sesiones (véase A/CN.9/766) y por la Comisión en su actual período de sesiones (véase el informe de la Comisión sobre su 46º período de sesiones, (A/68/17), párr. 197), y autoriza a la Secretaría a que edite y finalice el texto de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo teniendo en cuenta esas revisiones;

2. *Solicita* al Secretario General que publique, incluso en formato electrónico, el texto revisado de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo, junto con el texto de esta última, y que lo transmita a los gobiernos y los órganos interesados a fin de que sea de conocimiento y acceso generalizado;

3. *Recomienda* que los legisladores, encargados de formular políticas, jueces, profesionales de la insolvencia y otros interesados en los regímenes de la insolvencia transfronteriza y los procedimientos correspondientes tomen debidamente en consideración, cuando proceda, la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo;

4. *Recomienda también* a todos los Estados que sigan considerando la posibilidad de aplicar la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza, e invita a los Estados que hayan promulgado legislación basada en la Ley Modelo a que informen de ello a la Comisión.”

B. Finalización y aprobación de las recomendaciones legislativas sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia

199. La Comisión recordó su decisión de encomendar al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) el mandato de desarrollar varios temas, el segundo de los cuales se refería a la propuesta del Reino Unido (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.4), la Asociación Internacional de Profesionales en Reestructuración, Insolvencia y Quiebras (INSOL International) (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.3) y el International Insolvency Institute (A/CN.9/582/Add.6) en relación con las obligaciones de los directores y ejecutivos de una empresa en el período cercano a la insolvencia. La labor relativa a ese tema se ha centrado en la cuestión de las obligaciones que surgen en el período cercano a la insolvencia, pero solo son exigibles una vez que ha comenzado el procedimiento de insolvencia.

200. Con respecto a esa parte del mandato, la Comisión tuvo ante sí el texto propuesto sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la

insolvencia (A/CN.9/WG.V/WP.113) y las revisiones acordadas por el Grupo de Trabajo en su 43º período de sesiones (véase A/CN.9/766).

201. De conformidad con la hipótesis de trabajo adoptada por el Grupo de Trabajo, el texto propuesto se ha preparado como parte adicional de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia³² y, como tal, contiene un comentario y un conjunto de recomendaciones legislativas.

202. Habiendo examinado el texto, la Comisión aprobó las siguientes revisiones adicionales:

a) Supresión de las palabras “Como se señaló anteriormente” al comienzo de la tercera oración del párrafo 37;

b) Supresión de las palabras “por ejemplo” en la segunda oración del párrafo 51; y

c) Incorporación de una nota de pie de página con una remisión al párrafo 12 a) del glosario de la Guía Legislativa para aclarar el significado del término “gastos de administración” que figura en la recomendación 10.

203. Si bien no se propuso que el texto actual se revisara, se reiteraron las dudas acerca de la conveniencia de incluir el proyecto de recomendación 12, dado que no podía considerarse parte del régimen relativo a la insolvencia propiamente dicho sino que pertenecía al ámbito del derecho de sociedades o del derecho penal. Por otra parte, se expresó la opinión de que los tipos de medidas que se contemplaban estaban previstos en los regímenes de insolvencia de varias jurisdicciones y tenían por objeto alentar un comportamiento adecuado de los directores.

204. En su 973ª sesión, celebrada el 18 de julio de 2013, la Comisión adoptó la siguiente decisión:

“La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,

Reconociendo que la existencia de regímenes de insolvencia eficaces se considera cada vez más un factor de estímulo del desarrollo económico y la inversión, así como de fomento de la actividad empresarial y de preservación del empleo,

Considerando que los regímenes de la insolvencia eficaces, además de establecer un proceso jurídico previsible para hacer frente a las dificultades financieras de las empresas con problemas y el marco necesario para su reorganización eficiente o su liquidación ordenada, deberían permitir también que se examinaran las circunstancias que hubieran dado lugar a su insolvencia y, en particular, la conducta de sus directores en el período anterior al comienzo del procedimiento de insolvencia,

Observando que la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia³³, aunque aborda las obligaciones de los directores de una empresa una vez iniciado el procedimiento de insolvencia, no se ocupa de la

³² Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.05.V.10.

³³ Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.05.V.10.

conducta de los directores en el período cercano a la insolvencia ni de las obligaciones que podrían corresponderles en ese período,

Considerando que crear incentivos para que los directores adoptaran medidas adecuadas para hacer frente a los efectos de los problemas financieros de una empresa podría resultar decisivo para su reorganización exitosa o su liquidación, y que esos incentivos deberían formar parte de un régimen de la insolvencia eficaz,

Agradeciendo el apoyo y la participación de organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales interesadas en la reforma del régimen de la insolvencia en la preparación de una parte adicional de la Guía Legislativa dedicada a las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia,

Expresando su reconocimiento al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) por su labor de preparación de la cuarta parte de la Guía Legislativa, relativa a las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia,

1. *Aprueba* la cuarta parte de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia, cuyo texto figura en el documento A/CN.9/WG.V/WP.113, con las revisiones introducidas por el Grupo de Trabajo en su 43º período de sesiones (véase A/CN.9/766) y por la Comisión en su actual período de sesiones (véase el informe de la Comisión sobre su 46º período de sesiones (A/68//17), párr. 202), y autoriza a la Secretaría a que edite y finalice el texto de la cuarta parte de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia, teniendo en cuenta esas revisiones;

2. *Solicita* al Secretario General que publique, incluso en formato electrónico, el texto de la cuarta parte de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia, lo transmita a los gobiernos y otros órganos interesados y estudie la posibilidad de refundir las partes primera a cuarta de la Guía Legislativa y publicarlas, incluso en formato electrónico, en fecha posterior;

3. *Recomienda* a todos los Estados que utilicen la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia para evaluar la eficiencia económica de sus regímenes de la insolvencia y presten la debida atención a la Guía Legislativa cuando se dispongan a revisar o promulgar una ley relativa a la insolvencia, e invita a los Estados que hayan utilizado la Guía a que informen de ello a la Comisión.”

C. Finalización de las revisiones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial

205. La Comisión recordó la decisión por la que, en su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, había aprobado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial, así como la solicitud que había formulado a la Secretaría de que estableciera un mecanismo para actualizar continuamente la Perspectiva Judicial con la misma flexibilidad con que se había

elaborado, y garantizando que se mantuviera el tono neutral de su enunciado y que siguiera cumpliendo la finalidad enunciada en su texto³⁴.

206. La Comisión observó que la Secretaría había creado una junta de expertos para que la asesorara en la actualización de la Perspectiva Judicial, a fin de tener en cuenta la jurisprudencia reciente de interpretación de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza y de reflejar las revisiones propuestas de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza.

207. La Comisión tuvo ante sí el proyecto de actualizaciones propuestas de la Perspectiva Judicial (A/CN.9/778) y el informe del Grupo de Trabajo sobre su 43º período de sesiones (A/CN.9/766), en el que el Grupo de Trabajo había tomado nota de las actualizaciones del texto propuestas. La Comisión observó que el texto actualizado también se había puesto a disposición de los participantes en el Décimo Coloquio Judicial Multinacional, que habían organizado conjuntamente la Comisión, INSOL International y el Banco Mundial y se había celebrado en La Haya los días 18 y 19 de mayo de 2013.

208. La Comisión convino en que en el prefacio se deberían incluir los nombres y los Estados de origen de los integrantes de la junta de expertos a quienes se habían consultado las actualizaciones de la Perspectiva Judicial. Además, la Comisión hizo suya la sugerencia de que en el prefacio se debía aclarar que se incluían aquellos fallos pronunciados antes del 15 de abril de 2013, mientras que los posteriores a esa fecha se examinarían para su posible inclusión en una actualización posterior de la Perspectiva Judicial.

209. La Comisión tomó nota de las actualizaciones de la Perspectiva Judicial y felicitó a la Secretaría y a la junta de expertos por su labor de mantener vigente el texto, que era un valioso recurso para los jueces que se ocupaban de casos de insolvencia en los que se planteaban cuestiones transfronterizas. La Comisión autorizó a la Secretaría a que editara y finalizara el texto actualizado de la Perspectiva Judicial y solicitó que se publicara, incluso en formato electrónico, y se remitiera a los gobiernos junto con la solicitud de que lo hicieran llegar a las autoridades competentes a fin de que fuera de conocimiento y acceso generalizados.

D. Informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo V

210. La Comisión examinó los informes del Grupo de Trabajo sobre sus períodos de sesiones 42º y 43º (A/CN.9/763 y A/CN.9/766) y observó que en su 43º período de sesiones (Nueva York, 15 a 19 de abril de 2013) el Grupo de Trabajo había examinado los demás elementos del mandato señalado en el párrafo 195 del presente documento, particularmente en relación con la aplicabilidad del concepto de centro de los principales intereses a los grupos de empresas y la posible elaboración de una ley modelo o disposiciones modelo sobre el régimen de la insolvencia en que se regularan determinadas cuestiones del derecho internacional de la insolvencia, como las relativas a la jurisdicción, el acceso a los tribunales extranjeros y el

³⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 198.*

reconocimiento de los procedimientos extranjeros, de un modo que no impidiera preparar una convención, junto con otros temas para una posible labor futura.

211. La Comisión procedió a un intercambio preliminar de opiniones y señaló que, con posterioridad, en relación con el tema 16 del programa, se decidiría acerca de la prioridad de esas cuestiones y acerca de las cuestiones sobre una posible labor futura (véanse los párrafos 292 a 332 del presente documento). Se hizo referencia a la propuesta que figuraba en el documento A/CN.9/789 y a las conclusiones del Grupo de Trabajo consignadas en los párrafos 104 a 109 del documento A/CN.9/766. Se observó que las cuestiones relativas a un grupo de empresas en casos de insolvencia transfronteriza seguían siendo una esfera de preocupación fundamental y que al continuar la labor en ese ámbito se podría aprovechar el consenso existente respecto al centro de los principales intereses y las obligaciones de los directores en el contexto de las empresas individuales.

212. Se expresó apoyo en favor de celebrar un coloquio para que el Grupo de Trabajo pudiera reflexionar acerca del modo de tratar las cuestiones relativas a un grupo de empresas y otras partes de su mandato actual. Se sugirió que ese coloquio brindaría también la oportunidad de estudiar temas para la posible labor futura del Grupo de Trabajo, incluidos aquellos que pudieran ser de especial interés para los países en desarrollo, los particularmente pertinentes para hacer frente a la crisis financiera mundial, y asuntos concretos como el tratamiento de los derechos de los empleados en casos de insolvencia y la interrelación entre los regímenes de la insolvencia especializados elaborados para instituciones bancarias y financieras y el régimen general de la insolvencia. Se expresó también la opinión de que el Grupo de Trabajo V debía continuar con su mandato tal como estaba previsto. También se expresó la opinión de que no se debería proseguir con el mandato, puesto que el Grupo de Trabajo no contaba con un plan para lo que emanaría de su labor relativa a esas cuestiones, y que no debería emprenderse ninguna actividad al respecto hasta que se aclarase esa cuestión.

213. Una cuestión conexa era si ese coloquio debía reemplazar los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo previstos para 2013 y 2014. Algunos opinaron que no debía ser así y que, una vez celebrado el coloquio para aclarar cuál era el mejor modo de ejecutar el mandato existente, se debían celebrar los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo sin necesidad de ninguna otra aprobación de la Comisión para emprender la labor encaminada a terminar de cumplir el mandato existente. En cambio, otros opinaron que el coloquio debía reemplazar los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo previstos para 2013 y 2014 y que solo con la aprobación de la Comisión se podrían reanudar los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo. (Véase un examen más detallado del tema en los párrafos 324 a 326 del presente documento.)

VI. Examen de cuestiones relacionadas con la contratación pública

214. La Comisión recordó que había encargado a la Secretaría que realizara un estudio de los temas que no se habían tratado adecuadamente en la Ley Modelo de

la CNUDMI sobre la Contratación Pública (2011)³⁵ y su Guía para la incorporación al derecho interno y que tal vez merecieran documentos orientativos para apoyar la aplicación, interpretación y utilización eficaces de la Ley Modelo. La Comisión también había encargado a la Secretaría que estudiase opciones para publicar y divulgar los distintos recursos y documentos en sí, incluso cooperando con otros organismos pertinentes encargados de la introducción de reformas, y que emprendiera un estudio de los recursos y las publicaciones existentes de esos organismos a los que pudiera recurrirse a tal fin³⁶.

215. La Comisión examinó dos proyectos de documento preparados para prestar apoyo de ese modo a la Ley Modelo: “Directrices para la promulgación de un reglamento de la contratación pública de conformidad con el artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública” (A/CN.9/770) y “Glosario de términos relacionados con la contratación pública utilizados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública” (A/CN.9/771).

216. La Comisión adoptó la siguiente decisión relativa a esos documentos:

“La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,

Recordando que en su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, había aprobado su Ley Modelo sobre la Contratación Pública, y en su 45º período de sesiones, celebrado en 2012, había aprobado una guía para la incorporación de dicha ley al derecho interno³⁷,

Expresando su reconocimiento a la Secretaría por haber preparado los documentos “Directrices para la promulgación de un reglamento de la contratación pública de conformidad con el artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública” (A/CN.9/770) y “Glosario de términos relacionados con la contratación pública utilizados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública” (A/CN.9/771),

1. *Aprueba* los documentos “Directrices para la promulgación de un reglamento de la contratación pública de conformidad con el artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública” y “Glosario de términos relacionados con la contratación pública utilizados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública”;

2. *Solicita* al Secretario General que publique esos documentos, inclusive en formato electrónico, para darles amplia difusión entre los gobiernos y otras entidades interesadas y que haga todo lo posible para que se conozcan y estén disponibles de forma generalizada;

3. *Recomienda* que esos documentos sean examinados por los Estados y los organismos encargados de la introducción de reformas cuando se reformen los sistemas de contratación pública sobre la base de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública y su Guía para la incorporación

³⁵ *Ibid.*, anexo I.

³⁶ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párrs. 110 y 114.

³⁷ *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 192; y sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 46.

al derecho interno, a fin de respaldar la aplicación y utilización eficaces de la Ley Modelo.”

217. En relación con los demás temas sobre los que la Comisión había proporcionado orientaciones adicionales en su 45º período de sesiones, en 2012³⁸, y en respuesta a un informe verbal de la Secretaría sobre sus consultas con expertos en esos temas, la Comisión decidió que:

a) Las cuestiones de la gestión y administración de contratos y la planificación de las adquisiciones podían examinarse en el marco de cualquier actividad futura relacionada con las alianzas entre los sectores público y privado; así pues, por el momento no se debía seguir trabajando en esos temas (en lo que respecta a la futura labor en el ámbito de esas alianzas, véanse los párrafos 327 a 331 del presente documento);

b) La CNUDMI había recibido una publicación de un Estado miembro con información detallada sobre el fomento de la competencia en los procesos de adquisición y la mitigación de los riesgos de colusión, y se alentaba a la Secretaría a que hiciera referencia a ella en el sitio web de la CNUDMI;

c) En la Ley Modelo y la Guía se trataban con suficiente detalle los aspectos jurídicos relacionados con la utilización eficaz de los métodos de contratación de la Ley Modelo, la centralización de la contratación y los acuerdos marco, la sostenibilidad y las adquisiciones ambientales y el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los mercados de la contratación, pero se reconocía que otros organismos encargados de la introducción de reformas podían publicar material adicional sobre la aplicación y utilización de las disposiciones jurídicas en favor de las reformas, a medida que se fuera adquiriendo experiencia con esos instrumentos; cuando ese material pudiera respaldar la aplicación y utilización eficaces de la Ley Modelo, debía señalarse a la atención de la Comisión para que lo examinara a su debido tiempo;

d) Aunque los temas restantes estaban cobrando cada vez mayor importancia, no se abordaban en la Ley Modelo ni se trataban de forma detallada en la Guía (en particular, el uso de contratistas, cuestiones relacionadas con su capacidad, la suspensión, la inhabilitación profesional y la rectificación de la causa de inhabilitación); si existiera material adicional de fuentes externas que pudiera respaldar la aplicación y utilización eficaces de la Ley Modelo, o si se sugiriera que la preparación de material adicional por parte de la CNUDMI podría respaldar la aplicación y utilización de la Ley, la cuestión se plantearía a la Comisión para que la examinara a su debido tiempo;

e) La continuación de la labor de armonización entre la legislación en materia de contratación pública y otras ramas del derecho revestía menos prioridad y no se iba a seguir examinando por el momento.

³⁸ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 110.

VII. Solución de controversias en línea: informe sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo III

218. La Comisión recordó sus anteriores deliberaciones sobre la solución de controversias en línea³⁹ y tomó nota con aprecio de los progresos logrados por el Grupo de Trabajo III (Solución de Controversias en Línea), reflejados en los informes del Grupo de Trabajo sobre sus períodos de sesiones 22° a 27° (A/CN.9/716, A/CN.9/721, A/CN.9/739, A/CN.9/744, A/CN.9/762 y A/CN.9/769). La Comisión encomió a la Secretaría por los documentos de trabajo y los informes preparados para dichos períodos de sesiones.

219. En lo que respecta a las deliberaciones que había celebrado recientemente el Grupo de Trabajo, la Comisión recordó que en el seno de este se habían expresado opiniones divergentes sobre la naturaleza de la etapa final de los procedimientos de solución de controversias en línea en el marco del proyecto de reglamento que estaba debatiendo y que, a fin de conciliar esas opiniones, el Grupo de Trabajo había propuesto en su 26° período de sesiones un sistema basado en dos modalidades: una que terminaría en arbitraje y otra que no. Se recordó que el origen de esa propuesta estaba en el documento A/CN.9/762 y su anexo.

220. La Comisión señaló que en el 27° período de sesiones del Grupo de Trabajo varias delegaciones habían reiterado que este debía formular un sistema global para la solución de controversias en línea en el que tuvieran cabida tanto los ordenamientos jurídicos en que se establecía que los acuerdos de arbitraje previos a la controversia eran vinculantes para los consumidores como los que no (A/CN.9/769, párr. 16). La Comisión tomó nota de las dos propuestas estructurales formuladas en ese período de sesiones en relación con el reglamento: una de ellas abogaba por un reglamento aplicable únicamente a las operaciones entre empresas que precedería la elaboración de un reglamento aplicable a las operaciones entre empresas y consumidores, y la otra era una propuesta modificada de aplicar un sistema de dos modalidades. La Comisión observó también la determinación del Grupo de Trabajo en relación con esas propuestas, a saber, que no predominaba la opinión de descartar el sistema de dos modalidades en favor de un reglamento aplicable únicamente a las operaciones entre empresas a modo de etapa preliminar, y que todos los componentes de la propuesta modificada de un sistema de dos modalidades se colocarían entre corchetes para su ulterior examen y las inquietudes que suscitase esa propuesta se abordarían más adelante (A/CN.9/769, párrs. 14 a 43).

221. En su 45° período de sesiones, celebrado en 2012, la Comisión había decidido que el Grupo de Trabajo debía hacer lo siguiente: a) analizar el modo en que el proyecto de reglamento respondería a las necesidades de los países en desarrollo y los países en situaciones posteriores a conflictos, en particular en lo que se refería a la necesidad de que el proceso constase de una etapa de arbitraje, y posteriormente informar a la Comisión en un futuro período de sesiones; b) continuar examinando, en el marco de sus deliberaciones, los efectos del procedimiento de solución de controversias en línea en la protección del consumidor en los países en desarrollo y

³⁹ *Ibid.*, sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párrs. 338 y 341 a 343; sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), párrs. 252 y 257; sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 213; y sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párrs. 71 a 79.

los países desarrollados y en los países en situaciones posteriores a conflictos, incluidos los casos en que el consumidor fuera la parte demandada en un procedimiento de solución de controversias en línea; y c) seguir analizando distintos medios para garantizar la ejecución efectiva de los resultados de los procedimientos de solución de controversias en línea, inclusive el arbitraje y posibles opciones distintas del arbitraje. En ese período de sesiones, la Comisión reafirmó además el mandato del Grupo de Trabajo sobre la solución de controversias en línea respecto de las operaciones electrónicas transfronterizas en gran volumen y de poca cuantía, y alentó al Grupo de Trabajo a que prosiguiera su labor de la manera más eficiente posible⁴⁰.

222. Tras deliberar, la Comisión confirmó por unanimidad la decisión sobre la cuestión adoptada en su anterior período de sesiones⁴¹, a saber:

a) El Grupo de Trabajo debería analizar la manera en que el proyecto de reglamento respondería a las necesidades de los países en desarrollo y los países en situaciones posteriores a conflictos, en particular en lo que se refería a la necesidad de que el proceso constase de una etapa de arbitraje, y posteriormente informar a la Comisión en un futuro período de sesiones acerca de los resultados de dicho análisis;

b) El Grupo de Trabajo debería seguir examinando, en el marco de sus deliberaciones, los efectos del procedimiento de solución de controversias en línea en la protección del consumidor en los países en desarrollo y los países desarrollados y en los países en situaciones posteriores a conflictos, incluidos los casos en que el consumidor fuera la parte demandada en un procedimiento de solución de controversias en línea;

c) El Grupo de Trabajo debería seguir analizando distintos medios para garantizar la ejecución efectiva de los resultados de los procedimientos de solución de controversias en línea, inclusive el arbitraje y posibles opciones distintas del arbitraje;

d) Se reafirmó el mandato del Grupo de Trabajo sobre la solución de controversias en línea respecto de las operaciones electrónicas transfronterizas en gran volumen y de poca cuantía, y se alentó al Grupo de Trabajo a que prosiguiera su labor de la manera más eficiente posible.

VIII. Comercio electrónico: informe sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo IV

223. La Comisión recordó que en su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, había encargado al Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) que se ocupara de la cuestión de los documentos transmisibles electrónicos. En su período de sesiones en curso, la Comisión tuvo ante sí los informes del Grupo de Trabajo sobre la labor realizada en sus períodos de sesiones 46º (A/CN.9/761), celebrado en Viena del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2012, y 47º (A/CN.9/768), celebrado en Nueva York del 13 al 17 de mayo de 2013.

⁴⁰ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 79.

⁴¹ *Ibid.*

224. La Comisión observó que el Grupo de Trabajo, en su 46º período de sesiones, había convenido en que deberían formularse reglas generales basadas en un enfoque funcional que abarcaran diversos tipos de documentos transmisibles electrónicos y deberían prepararse proyectos de disposición en forma de una ley modelo, sin perjuicio de la decisión que se adoptara sobre la forma definitiva de esa labor (A/CN.9/761, párrs. 18 y 93). También se observó que el equipo jurídico de trabajo sobre gestión de la identidad de la American Bar Association había presentado un documento sobre la gestión de la identidad digital (A/CN.9/WG.IV/WP.120) para su examen en el período de sesiones en curso.

225. La Comisión observó que el Grupo de Trabajo, en su 47º período de sesiones, había tenido la primera oportunidad de examinar los proyectos de disposición sobre los documentos transmisibles electrónicos, en el entendimiento general de que se debía guiar en su trabajo por los principios de equivalencia funcional y neutralidad respecto de los medios tecnológicos y que no debía tratar cuestiones que se regían por el derecho sustantivo (A/CN.9/768, párr. 14).

226. Se expresó la opinión de que la labor relativa a los documentos transmisibles electrónicos debería tomar en consideración el Convenio estableciendo una Ley uniforme referente a las letras de cambio y pagarés a la orden (Ginebra, 7 de junio de 1930)⁴² y el Convenio estableciendo una Ley uniforme en materia de cheques (Ginebra, 19 de marzo de 1931)⁴³, puesto que la desmaterialización o la introducción de equivalentes electrónicos de esos instrumentos tal vez creara dificultades jurídicas en los Estados partes en esos convenios.

227. Observando que la labor actual del Grupo de Trabajo ayudaría enormemente a facilitar el comercio electrónico en el comercio internacional, la Comisión expresó su aprecio al Grupo de Trabajo por los avances realizados y encomió a la Secretaría por su labor.

228. La Comisión tomó nota de otras novedades en materia de comercio electrónico. En primer lugar, se observó que la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (Nueva York, 2005)⁴⁴ había entrado en vigor el 1 de marzo de 2013 y contaba con 3 Estados partes. Seguidamente se explicó que las disposiciones sustantivas de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas, que tenía 16 signatarios más, habían influido en algunos Estados que estaban revisando o promulgando legislación sobre comercio electrónico, y de ese modo esas disposiciones habían tenido el efecto, no previsto pero muy positivo, de actualizar y complementar la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico⁴⁵.

229. También se informó a la Comisión acerca de las actividades de asistencia técnica y coordinación en la esfera del comercio electrónico que había emprendido la Secretaría, incluso por conducto del Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico. Se observó que con las actividades de cooperación, como la participación de la Secretaría en la revisión de la recomendación número 14 del

⁴² Sociedad de Naciones, *Treaty Series*, vol. CXLIII, núm. 3313.

⁴³ *Ibid.*, vol. CXLIII, núm. 3316.

⁴⁴ Resolución 60/21 de la Asamblea General, anexo.

⁴⁵ Resolución 51/162 de la Asamblea General, anexo.

Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y el Comercio Electrónico, relativa a la autenticación de documentos comerciales por medios distintos a la firma, se aseguraba la coherencia de esos proyectos con los textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico. También se tomó nota de la coordinación con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, la Organización Mundial de Aduanas y la Comisión Europea.

230. Tras deliberar, la Comisión reafirmó el mandato del Grupo de Trabajo sobre los documentos transmisibles electrónicos y pidió a la Secretaría que la siguiera informando de las novedades de interés relativas al comercio electrónico.

IX. Asistencia técnica: reforma legislativa

231. La Comisión tuvo ante sí una nota de la Secretaría (A/CN.9/775) en la que se describían las actividades de cooperación y asistencia técnicas emprendidas con posterioridad a la fecha de la nota sobre el mismo tema presentada a la Comisión en su 45º período de sesiones, celebrado en 2012 (A/CN.9/753). La Comisión destacó la importancia de esas actividades de cooperación y asistencia técnicas y expresó su reconocimiento por las actividades emprendidas por la Secretaría que se reseñaban en el documento A/CN.9/775.

232. La Comisión observó que solo se podría seguir atendiendo a las solicitudes de actividades de cooperación y asistencia técnicas de los Estados y las organizaciones regionales si se disponía de los fondos necesarios para hacer frente a los costos conexos. Señaló además que, pese a las gestiones realizadas por la Secretaría para solicitar nuevas donaciones, los recursos de que se disponía en el Fondo Fiduciario para Simposios de la CNUDMI eran muy limitados. En consecuencia, seguían examinándose cuidadosamente las solicitudes de actividades de cooperación y asistencia técnicas, y el número de esas actividades (que en su mayoría se llevaban a cabo repartiendo los costos o sin costos para los interesados) era limitado. La Comisión pidió a la Secretaría que siguiera estudiando la posibilidad de emplear otras fuentes de financiación extrapresupuestaria, en particular, recurriendo en mayor medida a las misiones permanentes y a otros posibles socios de los sectores público y privado. Además, la Comisión alentó a la Secretaría a que buscara modos de cooperar con organizaciones internacionales, incluso mediante oficinas regionales, y con proveedores de asistencia bilateral en su labor de prestación de asistencia técnica, e hizo un llamamiento a todos los Estados, organizaciones internacionales y otras entidades interesadas a fin de que facilitaran esa cooperación y emprendieran cualquier otra iniciativa para utilizar con el máximo aprovechamiento las normas de la CNUDMI en materia de reforma legislativa.

233. La Comisión reiteró su llamamiento a todos los Estados, organizaciones internacionales y otras entidades interesadas a fin de que estudiaran la posibilidad de contribuir al Fondo Fiduciario para Simposios de la CNUDMI, de ser posible en forma de contribuciones plurianuales, o de contribuciones para fines concretos, con miras a facilitar la planificación y a dotar a la Secretaría de los medios necesarios para atender al número cada vez mayor de solicitudes de actividades de cooperación y asistencia técnicas presentadas por países en desarrollo y países de economía en transición. La Comisión expresó su reconocimiento al Gobierno de la República de Corea, por conducto de su Ministerio de Justicia, y al Gobierno de

Indonesia por las contribuciones al Fondo Fiduciario que habían efectuado desde la celebración del 45° período de sesiones de la Comisión, así como a las organizaciones que habían contribuido al programa proporcionando fondos o acogiendo seminarios.

234. La Comisión hizo un llamamiento a los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones, instituciones y particulares para que hicieran contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario establecido con objeto de ayudar a los países en desarrollo miembros de la Comisión a financiar los gastos de viaje. La Comisión expresó su agradecimiento a Austria por haber contribuido al Fondo Fiduciario de la CNUDMI desde la celebración del 45° período de sesiones de la Comisión, lo cual había permitido sufragar los gastos de viaje de países en desarrollo miembros de la CNUDMI.

X. Fomento de los modos necesarios para asegurar una interpretación y una aplicación uniformes de los textos jurídicos de la CNUDMI

235. La Comisión examinó el documento A/CN.9/777, titulado “Fomento de los modos necesarios para asegurar una interpretación y una aplicación uniformes de los textos jurídicos de la CNUDMI”, en el que se informaba de la situación actual del sistema de jurisprudencia relativa a los textos de la CNUDMI (CLOUT) y de los compendios de jurisprudencia relativos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.

236. La Comisión expresó su firme opinión de que el sistema CLOUT y los compendios constituían un instrumento importante para promover una interpretación uniforme del derecho mercantil internacional y observó con aprecio el número cada vez mayor de textos jurídicos de la CNUDMI que figuraban en los resúmenes del sistema CLOUT. Al 26 de abril de 2013 (fecha en que se publicó el documento A/CN.9/777), se habían preparado 128 números de resúmenes de jurisprudencia recopilada, que trataban de 1.234 casos. Esos casos guardaban relación con la Convención de Nueva York⁴⁶ y con los siguientes nueve textos de la CNUDMI:

- Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías (Nueva York, 1974)⁴⁷ y Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías enmendada por el Protocolo de 11 de abril de 1980 (Viena)⁴⁸

⁴⁶ La Comisión tal vez recuerde que en su 41° período de sesiones, celebrado en 2008, acordó que, de permitirlo los recursos, la Secretaría podría reunir y difundir información sobre la interpretación de la Convención de Nueva York en los tribunales. Por ese motivo el sistema CLOUT solo incluye jurisprudencia reciente sobre la Convención. Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1)*, párr. 360.

⁴⁷ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1511, núm. 26119.

⁴⁸ *Ibid.*, vol. 1511, núm. 26121.

- Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías (Hamburgo, 1978)⁴⁹
- Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa
- Ley Modelo de la CNUDMI sobre transferencias internacionales de crédito (1992)⁵⁰
- Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente (Nueva York, 1995)⁵¹
- Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985), con las modificaciones aprobadas en 2006⁵²
- Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, 1996⁵³
- Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza
- Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas.

Si bien la mayoría de los resúmenes publicados provenía de los Estados de Europa Occidental y otros Estados, se registró una leve disminución del número de resúmenes atribuibles a ese grupo regional y, a su vez, un módico aumento de los resúmenes de casos registrados en América Latina y el Caribe, con respecto a las cifras de 2012. El volumen de resúmenes de otros grupos regionales no había cambiado.

237. La red de corresponsales nacionales inició su mandato el primer día del 45º período de sesiones de la Comisión, en 2012. La red está integrada actualmente por 64 corresponsales que representan a 31 países. La Comisión observó que en el párrafo 7 del documento A/CN.9/777 figuraba información inexacta a ese respecto, puesto que no se había incluido a Dinamarca entre los países que habían nombrado recientemente a corresponsales nacionales. Desde la anterior nota a la Comisión (A/CN.9/748), los corresponsales nacionales habían presentado aproximadamente el 36% de los resúmenes publicados.

238. La Comisión observó con aprecio que la Secretaría había promovido por diversos medios el *Compendio de la CNUDMI sobre jurisprudencia relativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías* y el *Compendio de la CNUDMI de jurisprudencia sobre la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional*, y que la versión en inglés del primero de esos compendios se había impreso gracias al apoyo financiero y la colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. La Comisión observó también que el Compendio se estaba traduciendo a los otros cinco idiomas oficiales de las Naciones Unidas, y en algunos casos la traducción ya se había concluido.

⁴⁹ *Ibid.*, vol. 1695, núm. 29215.

⁵⁰ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/47/17)*, anexo I.

⁵¹ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 2169, núm. 38030, pág. 163.

⁵² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/40/17)*, anexo I; e *Ibid.*, sexagésimo primer período de sesiones, *Suplemento núm. 17 (A/61/17)*, anexo I.

⁵³ Resolución 51/162 de la Asamblea General, anexo.

Se informó a la Comisión de los progresos en la preparación del compendio sobre jurisprudencia relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza.

239. La Comisión tomó nota de la colaboración con los profesores G. Bermann y E. Gaillard y sus equipos, gracias a la cual se había creado una base de datos sobre la Convención de Nueva York, que incluía material utilizado en la preparación de la guía sobre esa Convención (véase el párrafo 137 del presente documento).

240. La Comisión acogió con beneplácito la noticia de que la Secretaría había encontrado recursos internos para actualizar y mejorar el sistema CLOUT a fin de hacerlo más fácil de utilizar. La Comisión expresó su aprecio a la Secretaría por la labor realizada en relación con el sistema CLOUT, observó el gran volumen de recursos que exigía ese sistema y de nuevo reconoció la necesidad de obtener más recursos para mantenerlo. Como había hecho en ocasiones anteriores⁵⁴, la Comisión exhortó a todos los Estados a que prestaran asistencia a la Secretaría para recabar financiación disponible a nivel nacional, a fin de garantizar la coordinación y ampliación del sistema.

XI. Situación y promoción de los textos de la CNUDMI

241. Basándose en una nota de la Secretaría (A/CN.9/773), la Comisión examinó la situación de los convenios, las convenciones y las leyes modelo dimanantes de su labor, así como la situación de la Convención de Nueva York. La Comisión tomó nota con aprecio de la información recibida desde su 45º período de sesiones acerca de las medidas de ratificación o de adhesión a tratados y de promulgación de textos legislativos. En particular, expresó su aprecio por la labor del Instituto Max Planck de Derecho Privado Comparado e Internacional (Hamburgo, Alemania) encaminada a buscar legislación por la que se incorporaban al derecho interno las leyes modelo de la CNUDMI e informar a la Secretaría de los resultados de su labor.

242. La Comisión también tomó nota con aprecio de las siguientes medidas y promulgaciones de las que se había informado a la Secretaría tras la presentación de la mencionada nota:

a) Convención de Nueva York: retiro de declaración por Mauricio (149 Estados partes);

b) Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (1996)⁵⁵: se había aprobado legislación basada en la Ley Modelo en Granada (2008), Omán (2008) y San Marino (2013). Se había aprobado legislación inspirada en los principios de la Ley Modelo en Bangladesh (2006) y en el estado de Georgia de los Estados Unidos (2009);

c) Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas (2001)⁵⁶: se había aprobado legislación basada en la Ley Modelo en Granada (2008)

⁵⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párr. 372.*

⁵⁵ Resolución 51/162 de la Asamblea General, anexo.

⁵⁶ Resolución 56/80 de la Asamblea General, anexo.

y San Marino (2013). Se había aprobado legislación inspirada en los principios de la Ley Modelo en Omán (2008);

d) Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional (2002)⁵⁷: se había aprobado legislación basada en la Ley Modelo en Bélgica (2005) y Luxemburgo (2012). Se había aprobado legislación inspirada en los principios de la Ley Modelo en Francia (2011), Suiza (2008) y el estado de Hawaii de los Estados Unidos (2013).

243. La Comisión observó que, a fin de hacerlo aún más útil, en el registro de medidas de ratificación o de adhesión a tratados y de promulgación de textos legislativos basados en las leyes modelo se podrían reflejar otros aspectos de los efectos de los textos de la CNUDMI. A ese respecto, tomó nota del Acuerdo sobre incendios y seguridad de los edificios, firmado en mayo de 2013 en Bangladesh⁵⁸. Se trataba de un acuerdo entre sindicatos y comerciantes de moda internacionales por el que se establecían unas normas mínimas de seguridad en el sector de la confección de Bangladesh, a la luz de la tragedia ocurrida en el edificio Rana Plaza. A fin de crear un régimen vinculante de solución de controversias, en el Acuerdo se hace referencia a la Convención de Nueva York y a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985), con las enmiendas aprobadas en 2006⁵⁹. El Acuerdo demuestra el amplio reconocimiento de la eficacia jurídica de esos textos y sirve además para recordar que esos textos gozan de la condición de normas ampliamente aceptadas y modelos para la creación de sistemas de rendición de cuentas mediante legislación.

244. Teniendo en consideración los efectos más amplios de los textos de la CNUDMI, la Comisión tomó nota de la bibliografía de obras recientemente publicadas relativas a su labor (A/CN.9/772) y observó con aprecio la influencia de sus guías legislativas, sus guías de prácticas y sus textos contractuales. A fin de facilitar que se aplicara un criterio exhaustivo en la creación de la bibliografía, y para fomentar que se diera a conocer la influencia de los textos de la CNUDMI, la Comisión exhortó a las organizaciones no gubernamentales, en particular a las invitadas a su período de sesiones anual, a que donaran ejemplares de sus revistas, informes anuales y demás publicaciones a la Biblioteca Jurídica de la CNUDMI, con el fin de examinarlos. A ese respecto, la Comisión expresó su agradecimiento al Instituto Alemán de Arbitraje por su decisión de donar todos los números, publicados y por publicar, de la revista alemana de arbitraje (*Zeitschrift für Schiedsverfahren*).

⁵⁷ Resolución 57/18 de la Asamblea General, anexo.

⁵⁸ Se puede consultar en: www.industrialunion.org/sites/default/files/uploads/documents/2013-05-13_-_accord_on_fire_and_building_safety_in_bangladesh_0.pdf (consultado el 16 de julio de 2013).

⁵⁹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/40/17), anexo I; e Ibid., sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/61/17), anexo I.*

XII. Coordinación y cooperación

A. Observaciones generales

245. La Comisión tuvo ante sí una nota de la Secretaría (A/CN.9/776) en la que se proporcionaba información sobre las actividades de las organizaciones internacionales que se ocupan del derecho mercantil internacional en las que la secretaría de la CNUDMI había participado desde la presentación a la Comisión de la nota más reciente sobre ese tema (A/CN.9/749). La Comisión observó con reconocimiento que la Secretaría había participado en actividades con varias organizaciones pertenecientes y ajenas al sistema de las Naciones Unidas, como, entre otras, el Banco Mundial, el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y el Comercio Electrónico, la Comisión Económica para Europa, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Comercio y Capacidad Productiva de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el UNIDROIT y la Unión Europea.

246. La Comisión observó que la actividad de coordinación de la Secretaría abarcaba temas examinados en todos los grupos de trabajo que tenía en ese momento la CNUDMI, y que la Secretaría participaba en grupos de expertos, grupos de trabajo y reuniones plenarias con el propósito de intercambiar información y conocimientos especializados y de evitar la duplicación del trabajo y de los productos resultantes. La Comisión observó también que esa labor entrañaba a menudo la necesidad de viajar a las reuniones de las organizaciones mencionadas en el párrafo 245 del presente documento y de gastar fondos asignados para viajes oficiales. La Comisión reiteró la importancia de la labor de coordinación que realizaba la CNUDMI en su calidad de órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el campo del derecho mercantil internacional y apoyó la utilización de fondos para viajes con ese fin.

247. A modo de ejemplo de la labor en curso, la Comisión mencionó con particular aprecio las actividades de coordinación en las que habían participado la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el UNIDROIT.

B. Coordinación y cooperación en materia de garantías reales

248. La Comisión tomó nota con reconocimiento de la labor de coordinación efectuada en los dos últimos decenios en relación con las garantías reales, por ejemplo en una publicación de las Naciones Unidas titulada “Textos sobre garantías reales preparados por la CNUDMI, la Conferencia de La Haya y el UNIDROIT: comparación y análisis de las principales características de los instrumentos internacionales relacionados con las operaciones garantizadas”⁶⁰. Hubo amplia coincidencia en que esos esfuerzos eran un excelente ejemplo del tipo de coordinación y cooperación que la Comisión venía promoviendo desde hacía

⁶⁰ Puede consultarse en www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/security/2011UNCITRAL_HCCH_Unidroit_texts.html (consultado el 1 de agosto de 2013).

años a fin de evitar la duplicación del trabajo y los conflictos entre los textos jurídicos preparados por diversas organizaciones.

249. Recordando el mandato que había conferido a la Secretaría en su 44° período de sesiones, celebrado en 2011⁶¹, la Comisión observó con reconocimiento la labor realizada por la Secretaría para: a) preparar, en cooperación con el Banco Mundial, un anteproyecto de un conjunto común de principios de la CNUDMI y el Banco Mundial sobre las operaciones garantizadas, que incorporaría las recomendaciones de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*; y b) cooperar estrechamente con la Comisión Europea con miras a establecer un enfoque coordinado de la cuestión de la ley aplicable a los efectos que tienen para los terceros las cesiones de créditos, teniendo en cuenta el enfoque utilizado en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional y en la Guía sobre las Operaciones Garantizadas. Hubo amplia coincidencia en que esa coordinación era particularmente importante y debía continuar. Tras deliberar, la Comisión renovó el mandato conferido a la Secretaría para que continuara esa labor de coordinación y la informara al respecto.

C. Informes de otras organizaciones internacionales

250. La Comisión tomó nota de las declaraciones formuladas en nombre de las siguientes organizaciones internacionales y regionales.

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT)

251. La Comisión escuchó una declaración formulada en nombre del UNIDROIT en la que se celebró la coordinación y cooperación que existía con la CNUDMI y se reafirmó el compromiso del Instituto de cooperar estrechamente con la Comisión.

252. El UNIDROIT informó de lo siguiente:

a) En su 92° período de sesiones (Roma, 8 a 10 de mayo de 2013), el Consejo de Administración del UNIDROIT había aprobado el documento titulado “Model Clauses for the Use of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts” (Cláusulas modelo para el uso de los Principios del UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales). La secretaria de la CNUDMI había aportado observaciones al proyecto de cláusulas modelo a fin de aclarar la relación entre los Principios del UNIDROIT y el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa. El Consejo de Administración había aprobado las cláusulas modelo y había incorporado las observaciones de la secretaria de la CNUDMI mediante una enmienda de las observaciones que acompañaban a las cláusulas modelo;

b) En el mismo período de sesiones, el Consejo de Administración del UNIDROIT había tomado nota del informe sobre la labor que podría realizarse en el futuro en relación con los contratos a largo plazo y había invitado a la secretaria del UNIDROIT a que adoptara medidas internas preliminares para determinar las cuestiones relacionadas con la inversión y otros contratos a largo

⁶¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 228.*

plazo que no se hubieran tratado debidamente en la edición de 2010 de los Principios del UNIDROIT;

c) El Consejo de Administración del UNIDROIT había tomado nota de los progresos realizados en las negociaciones para el establecimiento del registro internacional de material rodante ferroviario y de la primera reunión de la Comisión Preparatoria para el Establecimiento del Registro Internacional de Bienes Espaciales (Roma, 6 y 7 de mayo de 2013). En los trabajos de las comisiones preparatorias habían participado los siguientes Estados: Alemania, Arabia Saudita, Brasil, China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, India, Italia, República Checa y Sudáfrica. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Intergubernamental para el Transporte Internacional por Ferrocarril, así como varios otros participantes y representantes del mundo financiero y comercial, habían sido invitados a asistir al período de sesiones como observadores. El Consejo de Administración había pedido a la secretaría del UNIDROIT que siguiera atribuyendo alta prioridad a la promoción de ambos Protocolos del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil (Ciudad del Cabo, 2001)⁶²;

d) El Convenio de Ciudad del Cabo tenía ya 58 Estados partes, y el Registro establecido en virtud del Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico del mencionado Convenio⁶³ había alcanzado el notable nivel de casi 400.000 entradas desde su establecimiento en 2006;

e) El Consejo de Administración había seguido examinando las posibles adiciones al sistema de Ciudad del Cabo. En su 92º período de sesiones, el Consejo había tomado nota de los informes relativos a lo siguiente: a) un posible cuarto protocolo del Convenio de Ciudad del Cabo sobre el equipo agrícola, minero y de construcción, así como las expresiones de apoyo de varias asociaciones industriales con respecto a su posible impacto económico; b) un posible protocolo futuro sobre las embarcaciones y el equipo de transporte marítimo; y c) un posible protocolo futuro sobre el equipo de generación de energía eólica frente a las costas. El Consejo de Administración había convenido en continuar con la labor preliminar relativa al posible cuarto protocolo, sobre el equipo agrícola, minero y de construcción, de mediana prioridad, y había pedido a la secretaría del UNIDROIT que preparara un estudio de viabilidad sobre la existencia de las condiciones adecuadas para proseguir los trabajos relativos a los otros dos temas;

f) El Consejo de Administración había aprobado el proyecto de principios sobre la ejecutabilidad de las decisiones sobre compensación global de clausura, junto con las observaciones correspondientes;

g) Más entrado el año, el Comité del UNIDROIT sobre los mercados emergentes celebraría en Estambul su tercera reunión, con el fin de establecer el alcance de una guía legislativa sobre los principios y normas para fomentar el comercio de valores en los mercados emergentes, y la metodología para elaborarla;

h) Se habían celebrado dos períodos de sesiones del grupo de trabajo del UNIDROIT encargado de preparar una guía jurídica sobre la agricultura por

⁶² Puede consultarse en www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm (consultado el 1 de agosto de 2013).

⁶³ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 2367, núm. 41143.

contrato, proyecto al que el Consejo de Administración del UNIDROIT había atribuido alta prioridad con vistas a su finalización sustantiva en 2014. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos habían participado activamente en la preparación de la guía. El Consejo había reafirmado su interés en una posible labor futura sobre los aspectos de derecho privado de las inversiones y la financiación agrícolas (incluidos los contratos de inversión agraria, los regímenes de tenencia de la tierra y la estructura jurídica de las empresas agrícolas) y había alentado a la secretaría del UNIDROIT a reexaminar esas cuestiones una vez que se hubiera ultimado la guía jurídica sobre la agricultura por contrato.

253. En cuanto a las cláusulas modelo, la Comisión recordó las observaciones formuladas en su 40º período de sesiones con respecto a su aprobación de la edición de 2004 de los Principios del UNIDROIT, en que había explicado en detalle su posición sobre la relación correcta entre los Principios del UNIDROIT y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa⁶⁴. Se reiteró que los Principios del UNIDROIT no debían interpretarse como los “principios generales” en que se basaba la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa. Se observó que esos “principios generales” estaban integrados en la jerarquía interpretativa del artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa. También se señaló que, para que los Principios del UNIDROIT desplazaran a los principios mencionados en el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa, era necesario que las partes excluyeran contractualmente la aplicación de dicho artículo. Aunque tomó nota de la enmienda introducida en las observaciones que acompañaban a las cláusulas modelo, la Comisión propuso que, para evitar toda confusión en cuanto a las funciones de los Principios del UNIDROIT y de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa, y en cuanto a la relación entre ambos instrumentos, esa cuestión se examinara más a fondo en el coloquio que se celebraría con ocasión del 35º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa, o en otra reunión (véase el párrafo 315 del presente documento).

254. La Comisión tomó nota de la decisión del Consejo de Administración del UNIDROIT de solicitar la cooperación sustantiva de la CNUDMI. Tras deliberar, la Comisión convino en que debería intensificar su cooperación con el UNIDROIT y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, especialmente en las esferas de intersección de sus respectivas actividades. La Comisión expresó también su amplio apoyo a la propuesta de que en su siguiente período de sesiones se le presentara un informe, preparado conjuntamente por la secretaría de la CNUDMI y el UNIDROIT, en el que se pusieran de relieve los posibles proyectos conjuntos.

Unión Europea

255. La Comisión escuchó una declaración de la Comisión Europea sobre su propuesta relativa a una normativa común de compraventa europea. Se expusieron las consideraciones que justificaban esa propuesta, incluidos los obstáculos jurídicos

⁶⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17), párrs. 209 a 213.*

al comercio que se derivaban de las divergencias entre los distintos derechos contractuales. Se observó que la propuesta se refería a un instrumento de derecho contractual facultativo que podría seleccionarse en las operaciones transfronterizas entre empresas y consumidores, y en las operaciones transfronterizas entre empresas en que una de las partes fuera una pequeña o mediana empresa. Se señaló asimismo que la normativa común de compraventa europea, tal como se había propuesto, podría seleccionarse en toda operación en que al menos una de las partes estuviera situada en la Unión Europea. Se mencionó también la influencia de los instrumentos internacionales, en particular la de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa y la de los Principios del UNIDROIT, en la propuesta de la Comisión Europea. Por último, se señaló que la propuesta estaba todavía en estudio en el marco de los procedimientos legislativos de la Unión Europea.

Banco Mundial

256. La Comisión escuchó una declaración formulada en nombre del Banco Mundial en la que se expresó reconocimiento a la CNUDMI y su secretaría por su continua cooperación con el Banco Mundial. Se observó que durante los últimos años las actividades de la CNUDMI y sus grupos de trabajo habían impulsado considerablemente la labor del Banco Mundial en apoyo de la modernización de las condiciones jurídicas propicias al crecimiento económico y el comercio. En particular, se pusieron de relieve las actividades que realizaban las dos organizaciones para establecer marcos jurídicos uniformes en los ámbitos de la contratación pública, el arbitraje y la conciliación, la insolvencia y las operaciones garantizadas.

D. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales invitadas a asistir a los períodos de sesiones de la CNUDMI y de sus grupos de trabajo

257. En su período de sesiones en curso, la Comisión recordó que, en su 43° período de sesiones, celebrado en 2010, había aprobado el resumen de las conclusiones sobre su reglamento y sus métodos de trabajo⁶⁵. En el párrafo 9 del resumen se señalaba que la Comisión había decidido elaborar y actualizar debidamente una lista de las organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales con las que hubiera mantenido una prolongada relación de cooperación y a las que hubiera invitado a asistir a sus períodos de sesiones. La Comisión recordó también que, atendiendo a una petición suya⁶⁶, la Secretaría había reestructurado la información presentada por vía electrónica acerca de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales invitadas a asistir a los períodos de sesiones de la CNUDMI y de sus grupos de trabajo, así como la manera de comunicar esa información a los Estados, y que esa reestructuración se había efectuado a satisfacción de la Comisión⁶⁷.

258. La Comisión tomó nota de que, desde su 45° período de sesiones, celebrado en 2012, se habían añadido a la lista de organizaciones no gubernamentales

⁶⁵ *Ibid.*, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), anexo III.

⁶⁶ *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párrs. 288 a 298.

⁶⁷ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párrs. 176 a 178.

invitadas a asistir a los períodos de sesiones de la CNUDMI y de sus grupos de trabajo las siguientes organizaciones: Instituto Europeo de Derecho (www.europeanlawinstitute.eu), Junta de Arbitraje Mercantil de Corea (www.kcab.or.kr) y Panel of Recognised International Market Experts in Finance (www.primefinancedisputes.org).

259. En respuesta a una pregunta sobre la inclusión en la lista de la Junta de Arbitraje Mercantil de Corea, se explicó que la afiliación nacional de una organización no gubernamental no era un factor decisivo a la hora de decidir si se la invitaba a asistir a los períodos de sesiones de la CNUDMI. La Comisión recordó que varias organizaciones no gubernamentales nacionales estaban invitadas a asistir a los períodos de sesiones de la CNUDMI debido a la importante función que desempeñaban en la elaboración de textos jurídicos no solo en su propia jurisdicción sino también en las jurisdicciones de una determinada región o en el mundo entero, lo que se reflejaba en su composición por lo general multinacional. También se tenía en cuenta la necesidad de lograr una representación equilibrada de las organizaciones no gubernamentales de distintas regiones geográficas y de grupos de países con diferentes grados de desarrollo. Asimismo, se hacía lo posible por evitar la representación excesiva de las organizaciones de un determinado país o región, o de las organizaciones con una esfera de competencia particular que ya estuviera suficientemente representada en la Comisión.

260. La Comisión recordó los criterios que aplicaba la Secretaría al decidir invitar a una nueva organización a los períodos de sesiones de la CNUDMI. La Comisión reafirmó su entendimiento, recogido en el párrafo 10 del resumen de las conclusiones sobre su reglamento y sus métodos de trabajo (véase el párr. 257 del presente documento), de que correspondía a la Secretaría informar a los Estados miembros de la Comisión de su decisión de invitar a una nueva organización no gubernamental a asistir a los períodos de sesiones de la CNUDMI, y a la Comisión adoptar la decisión final cuando se planteara una objeción a esa decisión. La Comisión confirmó también su entendimiento de que las invitaciones cursadas a las organizaciones no gubernamentales para que asistieran a los períodos de sesiones de la CNUDMI y de sus grupos de trabajo no influían en la condición de observador de esas organizaciones ante ningún órgano del sistema de las Naciones Unidas, y de que la condición de una organización no gubernamental ante el Consejo Económico y Social no influía en la decisión de invitar o no a esa organización a asistir a los períodos de sesiones de la CNUDMI. La lista de organizaciones no gubernamentales invitadas a asistir a los períodos de sesiones de la CNUDMI se confeccionaba y ponía a disposición de los Estados con el único fin de informarlos de las organizaciones que se invitaría a los períodos de sesiones.

261. Se señaló que los criterios aplicados por la Secretaría al decidir invitar a una nueva organización no gubernamental a asistir a los períodos de sesiones de la CNUDMI y el procedimiento utilizado para aplicar esos criterios debían ser lo más objetivos posible. También se expresó la opinión de que la Secretaría debería informar a los Estados miembros de la Comisión antes de cursar una invitación a una nueva organización no gubernamental y antes de añadir esa organización a la lista. Se recordó que esas cuestiones ya se habían examinado detenidamente en períodos de sesiones anteriores de la Comisión. La Comisión reafirmó el compromiso alcanzado acerca de esas cuestiones, que se había recogido en los

párrafos 9 y 10 del resumen de las conclusiones sobre sus métodos de trabajo antes mencionado.

XIII. Centros regionales de la CNUDMI

262. La Comisión tomó nota de las actividades realizadas por el Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico con posterioridad a la fecha del informe sobre ese mismo tema presentado a la Comisión en su 45º período de sesiones, celebrado en 2012, y que se reseñaban en los párrafos 51 a 70 del documento A/CN.9/775.

263. El representante de la República de Corea hizo referencia a la estrecha colaboración que su Gobierno, en particular su Ministerio de Justicia, había mantenido con el Centro Regional para Asia y el Pacífico, y dio algunos ejemplos de los resultados de esa colaboración. Se indicó el interés de la República de Corea por seguir trabajando conjuntamente.

264. El representante de Kenya confirmó que su Gobierno seguía estudiando la posibilidad de acoger un centro regional de la CNUDMI en Nairobi⁶⁸.

265. La Comisión destacó la importancia de las tareas asignadas al Centro Regional para Asia y el Pacífico y expresó su reconocimiento por las actividades emprendidas.

266. La Comisión reconoció con agradecimiento la contribución de la República de Corea al Centro Regional para Asia y el Pacífico y acogió con beneplácito el interés continuado del Gobierno de Kenya por establecer un centro regional. La Comisión solicitó a la Secretaría que la mantuviera al corriente de las novedades referentes al funcionamiento del Centro Regional para Asia y el Pacífico y a la creación de otros centros regionales de la CNUDMI, en particular en lo relativo a su financiación y sus presupuestos.

XIV. Función que desempeña la CNUDMI en el fomento del estado de derecho a nivel nacional e internacional

A. Introducción

267. La Comisión recordó que el tema relativo a la función que desempeñaba la CNUDMI en el fomento del estado de derecho a nivel nacional e internacional se venía incluyendo en el programa de la Comisión desde su 41º período de sesiones, celebrado en 2008⁶⁹, en respuesta a la invitación de la Asamblea General a la Comisión de que, en el informe que le presentara, formulara observaciones sobre sus funciones actuales en la promoción del estado de derecho⁷⁰. La Comisión recordó también que, desde ese período de sesiones, en sus informes anuales a la

⁶⁸ *Ibid.*, párr. 192.

⁶⁹ La decisión de la Comisión de incluir el tema en su programa puede consultarse en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17)*, segunda parte, párrs. 111 a 113.

⁷⁰ Resoluciones de la Asamblea General 62/70, párr. 3; 63/128, párr. 7; 64/116, párr. 9; 65/32, párr. 10; y 66/102, párr. 12.

Asamblea General había formulado observaciones sobre sus funciones en la promoción del estado de derecho a nivel nacional e internacional, inclusive en situaciones de reconstrucción posteriores a conflictos. La Comisión expresó su convencimiento de que la promoción del estado de derecho en las relaciones comerciales debería formar parte integrante del programa general de las Naciones Unidas de promoción del estado de derecho a nivel nacional e internacional, incluso por conducto del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, que recibía el respaldo de la Dependencia sobre el Estado de Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario General⁷¹. La Comisión observó con satisfacción que la Asamblea General había hecho suya esa opinión⁷².

268. La Comisión recordó además que en su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, había indicado que estimaba esencial mantener un diálogo frecuente con el Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, por conducto de la Dependencia sobre el Estado de Derecho, a fin de mantenerse al corriente de los progresos realizados en la integración de la labor de la CNUDMI en las actividades conjuntas de las Naciones Unidas en pro del estado de derecho. Con ese fin, la Comisión había solicitado a la Secretaría que organizara una sesión informativa a cargo de la Dependencia sobre el Estado de Derecho cada dos años, cuando los períodos de sesiones de la Comisión se celebraran en Nueva York⁷³. Por tanto, durante el 45º período de sesiones de la Comisión, celebrado en Nueva York en 2012, tuvo lugar una sesión informativa⁷⁴.

269. En ese período de sesiones se había informado a la Comisión de los progresos realizados en cuanto al logro de un mayor conocimiento de la labor de la CNUDMI y la integración de esa labor en las actividades realizadas por las Naciones Unidas y otras organizaciones en relación con el estado de derecho. También se había informado a la Comisión de los preparativos de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional programada para septiembre de 2012 y los resultados previstos de la reunión. En ese mismo período de sesiones, la Comisión había formulado su posición en cuanto a la manera de asegurar que determinados aspectos de la labor de la CNUDMI quedaran debidamente reflejados en la reunión de alto nivel y en su documento final, así como en su mensaje para la propia reunión de alto nivel⁷⁵.

⁷¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1)*, párr. 386; *ibid.*, sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párrs. 413 a 419; *ibid.*, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), párrs. 313 a 336; *ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párrs. 299 a 321; e *ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párrs. 195 a 227.

⁷² Resoluciones de la Asamblea General 63/120, párr. 11; 64/111, párr. 14; 65/21, párrs. 12 a 14; 66/94, párrs. 15 a 17, y 67/89, párrs. 16 a 18.

⁷³ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17)*, párr. 335.

⁷⁴ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párrs. 195 a 227.

⁷⁵ *Ibid.*, párrs. 211 a 223.

B. Novedades pertinentes desde el 45° período de sesiones de la Comisión

270. En su 46° período de sesiones, la Comisión escuchó un informe oral del Presidente de su 45° período de sesiones sobre la aplicación de las decisiones pertinentes adoptadas por la Comisión en dicho período de sesiones⁷⁶. En particular, se informó de que, por invitación especial de la Asamblea General, el Presidente del 45° período de sesiones de la CNUDMI había formulado una declaración ante la reunión de alto nivel en la que había puesto de relieve que los efectos del estado de derecho y el desarrollo económico se reforzaban mutuamente y había destacado la importancia de la labor que realizaba la CNUDMI para promover el estado de derecho en las relaciones comerciales y en un contexto más amplio. La Comisión tomó nota con satisfacción de la Declaración de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional⁷⁷, en cuyo párrafo 7 los Estados Miembros habían reafirmado que el estado de derecho y el desarrollo estaban estrechamente relacionados y se reforzaban mutuamente, y habían expresado su convicción de que esa interrelación debía considerarse en la agenda internacional de desarrollo posterior a 2015. En particular, la Comisión observó con agrado que, en el párrafo 8 de la Declaración, los Estados habían reconocido la importancia de los marcos jurídicos justos, estables y previsibles para crear desarrollo, crecimiento económico y empleo inclusivos, sostenibles y equitativos, generar inversiones y facilitar la actividad empresarial y, a ese respecto, habían encomiado la labor que realizaba la CNUDMI.

271. La Comisión expresó su agradecimiento al Presidente de su 45° período de sesiones por el informe presentado y por haberse asegurado de transmitir el mensaje de la CNUDMI a la reunión de alto nivel y de que los aspectos de la labor de la Comisión hubieran quedado debidamente reflejados en la reunión de alto nivel y en su documento final.

272. La Comisión también tomó nota con satisfacción de la participación del Presidente de su 45° período de sesiones en el debate temático de la Asamblea General sobre el tema “Iniciativa empresarial para el desarrollo”, celebrado en Nueva York el 26 de junio de 2013, y en una conferencia organizada conjuntamente por la Comisión de Consolidación de la Paz y el Pacto Mundial sobre el potencial del sector privado para ayudar a los países frágiles a salir de situaciones de conflicto. La Comisión respaldó las iniciativas encaminadas a que en todo el sistema de las Naciones Unidas se cobrara conciencia de la labor realizada por la CNUDMI y su pertinencia para otros ámbitos de la labor de las Naciones Unidas.

273. También se informó a la Comisión de que su secretaría, a petición de la Dependencia sobre el Estado de Derecho, había preparado un proyecto de nota orientativa del Secretario General sobre la promoción del estado de derecho en las relaciones comerciales. El proyecto de nota orientativa, que estaba examinando la Dependencia y posteriormente se transmitiría a los miembros del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho para que formularan observaciones al respecto, se basaba en las decisiones adoptadas por la Comisión desde 2008 en relación con el tema del programa que tenían por objeto: a) fortalecer de forma sostenida la capacidad de los Estados para promover el estado de derecho

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Resolución 67/1 de la Asamblea General.

en las relaciones comerciales, de ser necesario con la asistencia de la comunidad internacional; y b) reforzar la capacidad de las Naciones Unidas para atender con eficacia, cuando se le solicitara, las necesidades de los Estados para crear dicha capacidad en el plano local. La nota tenía por objeto ser pertinente a las actividades de las Naciones Unidas relativas al estado de derecho, en particular las que promovían el desarrollo económico en diversas situaciones, incluidos contextos de prevención de conflictos, reconstrucción posterior a conflictos y desarrollo. La Comisión solicitó a la Secretaría que señalase la nota orientativa a la atención de la Comisión una vez que se hubiera publicado, a fin de darle la mayor difusión posible.

274. La Comisión recibió información sobre otras novedades ocurridas desde su último período de sesiones con respecto a la aplicación de la agenda del estado de derecho de las Naciones Unidas. En particular, se la informó de las iniciativas emprendidas en todo el sistema de las Naciones Unidas para formular la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas después de 2015, de la cual era parte esencial el estado de derecho. Se la informó, en especial, de la labor del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del comité intergubernamental de expertos en financiación del desarrollo sostenible.

275. La Comisión observó la pertinencia de su labor para esas y otras actividades realizadas en todo el sistema de las Naciones Unidas. Pidió a su Mesa del período de sesiones en curso y a su secretaría que tomaran medidas apropiadas para asegurar que no se pasaran por alto las esferas de trabajo de la CNUDMI ni el papel de la CNUDMI en la promoción del estado de derecho y el desarrollo sostenible, y que le presentaran en su siguiente período de sesiones un informe sobre la labor realizada en ese sentido.

C. Observaciones formuladas a la Asamblea General sobre las funciones actuales de la CNUDMI en la promoción del estado de derecho

276. La Comisión tomó nota de la resolución 67/97 de la Asamblea General, relativa al estado de derecho en los planos nacional e internacional. En el párrafo 14 de esa resolución, la Asamblea había invitado a la Comisión a que siguiera formulando observaciones, en sus informes a la Asamblea General, sobre sus funciones actuales en la promoción del estado de derecho. En el párrafo 17 de la resolución, la Asamblea había decidido que los próximos debates de la Sexta Comisión que se celebrarían en 2013 en relación con el tema del programa titulado “El estado de derecho en los planos nacional e internacional” se centrarían en el subtema “El estado de derecho y el arreglo pacífico de controversias internacionales”. En consecuencia, la Comisión decidió centrar sus observaciones a la Asamblea General en sus funciones en la promoción del estado de derecho y el arreglo pacífico de las controversias internacionales.

277. Para facilitar la formulación de observaciones sobre ese subtema por la Comisión, de conformidad con la mencionada invitación de la Asamblea General, la Secretaría organizó una mesa redonda con la participación de expertos en las esferas de trabajo de la CNUDMI relacionadas con ese subtema (arbitraje y conciliación y solución de controversias en línea).

1. Resumen de la sesión informativa sobre el estado de derecho respecto de las funciones de la CNUDMI en la promoción del estado de derecho y el arreglo pacífico de las controversias internacionales

278. La mesa redonda inició su debate poniendo de relieve la importante función de las normas de arbitraje comercial internacional en el fortalecimiento del estado de derecho mediante el arreglo pacífico de las controversias internacionales. El arbitraje era una esfera en la que la CNUDMI había venido trabajando desde su creación, y la CNUDMI había ganado renombre por su elaboración de instrumentos jurídicos fundamentales, como el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje, así como por la vigilancia de la aplicación efectiva de la Convención de Nueva York de 1958.

279. Se señaló que el arbitraje comercial internacional había sido uno de los medios más eficaces para el arreglo de las controversias económicas internacionales, por ejemplo las controversias transfronterizas sobre inversiones en recursos naturales. Se adujo que, de resultas de ello, tal vez el arbitraje comercial internacional hubiera reducido las posibilidades de que surgieran conflictos entre los Estados al obviar la necesidad de que estos se enfrentaran directamente en nombre de sus ciudadanos agraviados mediante represalias, el respaldo de demandas u otros medios. Además, podía haber contribuido a evitar el agravamiento de situaciones inestables (por ejemplo, al evitar que las sociedades volvieran a caer en una situación de conflicto).

280. Los oradores pusieron de relieve las características específicas por las que el arbitraje internacional era un instrumento valioso para el arreglo pacífico de controversias, en especial de las controversias surgidas en un marco de relaciones inestables y de carga política (por ejemplo, las inversiones transfronterizas en industrias extractivas, las controversias posteriores a conflictos relacionadas con daños transfronterizos, la incautación de propiedades o las reclamaciones de territorio). Entre esas preciadas características, los oradores señalaron la flexibilidad (la posibilidad de que las partes litigantes aplicaran un procedimiento especial adaptado específicamente a su controversia, en lugar de verse sujetas a los procedimientos establecidos de un tribunal local) y la neutralidad mediante la desnacionalización del foro jurídico de arbitraje de las controversias (el tribunal arbitral era independiente de las partes litigantes y estaba fuera del alcance de toda interferencia o instrucción proveniente de los gobiernos respectivos, y gozaba de facultades para dictar fallos en su jurisdicción propia).

281. Se indicó que la neutralidad del foro tenía un valor especial en las situaciones posteriores a conflictos y en otras situaciones inestables en las que solía estar excluido el recurso a tribunales del Estado en conflicto (porque los tribunales fueran disfuncionales, por sospecha de sesgo o incluso hostilidad por parte de estos, lo que también planteaba cuestiones relativas a la seguridad personal, o por la falta de independencia judicial, incluido el caso en que un tribunal nacional debiera determinar la legalidad de los actos de su propio gobierno).

282. Se dijo que los instrumentos de la CNUDMI en la esfera del arbitraje comercial internacional proporcionaban medios prácticos para velar por que las mencionadas características distintivas del arbitraje internacional funcionaran en la práctica. En lo tocante a la flexibilidad, se dijo que el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI ofrecía una gran flexibilidad para adaptar el procedimiento a los requisitos de la controversia al permitir que las partes definieran las cuestiones que habían de resolverse, el número de árbitros, la identidad de estos, el foro y el derecho aplicable. Se observó que, una vez constituido, el tribunal tenía poderes inherentes para elaborar, en consulta con las partes, procedimientos propios sobre aspectos como el plazo en el que se dictaría el laudo arbitral, el número y el orden de los alegatos y la manera en que el tribunal obtendría pruebas. Con respecto a la neutralidad, se afirmó que la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje había sido el instrumento que mejor había logrado asegurar un enfoque independiente y armonizado del arbitraje internacional.

283. Los oradores también encomiaron los esfuerzos desplegados por la CNUDMI en cooperación con otros interesados para lograr una adhesión casi universal a la Convención de Nueva York de 1958 (que contaba con 149 Estados partes) y a su cumplimiento eficaz y su interpretación y aplicación uniformes mediante la reunión y divulgación de la jurisprudencia y otros materiales con ella relacionados. Se afirmó que la contribución de la Convención al fortalecimiento del estado de derecho era indiscutible: había cimentado el arbitraje internacional al proporcionar durante más de 50 años un conjunto común de normas para el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales internacionales. (Sobre esta cuestión, véase también el párrafo 136 del presente documento.)

284. Se indicó que el marco que proporcionaban esos instrumentos era un medio eficaz de atraer las inversiones necesarias para el desarrollo sostenible y la creación de capacidad, lo que a su vez podría impedir eficazmente el surgimiento de muchos conflictos que actualmente eran provocados por factores económicos.

285. Los oradores recordaron que la Comisión había aprobado en el período de sesiones en curso el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado (véase el párrafo 128 del presente documento). Con relación a la definición de estado de derecho expresada en los documentos de las Naciones Unidas⁷⁸, en que se hace referencia explícitamente a la transparencia procesal y legal, se subrayó que, sin esa transparencia, los demás requisitos fundamentales del estado de derecho, como la rendición de cuentas, la legalidad, la equidad en la aplicación de la ley y la no arbitrariedad, no se podían cumplir. Asimismo, se destacó la influencia que podía tener el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia para que se reunieran todos esos elementos fundamentales del estado de derecho, sobre todo en una esfera como la de la utilización de los recursos públicos, en la cual la transparencia era muy necesaria. El Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia, según se dijo, abarcaba casi todos los aspectos de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, y era matizado y equilibrado. Sin embargo, para alcanzar los objetivos que se perseguía con él era preciso que se aplicara de manera efectiva. Así pues, según los oradores, la importante labor de la CNUDMI

⁷⁸ Véase el informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos (S/2004/616), párr. 6.

debía proseguir: la Comisión no solo debía preparar en breve un convenio en el que se previera un mecanismo para facilitar la aplicabilidad del Reglamento a los tratados de inversiones existentes, sino también adoptar medidas encaminadas a la aplicación práctica del Reglamento, la reunión y difusión de la información pertinente prevista en él y el fomento de buenas prácticas con respecto a su uso. A esa propuesta se respondió que ello debía ponderarse con la necesidad de respetar la base sobre la que se adoptaban las decisiones relativas a inversiones, y que cambiar las normas aplicables a esas decisiones iba en contra del estado de derecho.

286. Seguidamente, la Comisión escuchó la sugerencia de que se aprovechara en mayor medida la mediación y la función de los tribunales nacionales en la solución de controversias internacionales de carácter económico. Se destacó el valor de la mediación como método flexible, poco oneroso y rápido para solucionar controversias y como mecanismo eficaz para alcanzar pronto una solución amigable entre partes litigantes. Se presentaron datos que mostraban cómo en muchos casos de arbitrajes entre inversionistas y Estados las controversias se habían resuelto amigablemente antes de la emisión del laudo final. Asimismo, se señaló que, a pesar de la preferencia por la solución amigable de las controversias, la mediación no se utilizaba ni conocía de forma generalizada. Su relativa impopularidad se debía en parte a las desventajas que se veían a ese mecanismo, concretamente la incertidumbre en cuanto a la aplicación de los resultados de la mediación, así como el hecho de que en la legislación no se reconociera de forma explícita a ninguna entidad la facultad de negociar en nombre del Estado en el marco de procedimientos de mediación. Muchos países carecían de una legislación consolidada que tratara en profundidad todos los aspectos relacionados con la mediación comercial o la capacidad para ocuparse de la mediación de controversias de carácter comercial. Esa situación se daba a pesar de que numerosas jurisdicciones estudiadas por el Banco Mundial preveían la remisión por parte de los tribunales de controversias de carácter comercial a mecanismos de mediación o conciliación cuando ya se habían entablado actuaciones judiciales. Se destacó la función del Reglamento de Conciliación de la CNUDMI (1980)⁷⁹ y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional⁸⁰ en el refuerzo del marco interno para la mediación: se consideró que contar con normas de mediación sólidas a nivel nacional era indispensable para promover la mediación en las controversias internacionales y garantizar la aplicación de al menos algunas salvaguardias en materia de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción en las negociaciones celebradas en el marco de procedimientos de mediación.

287. La Comisión también escuchó una ponencia sobre el carácter cambiante de la solución de controversias en línea y su potencial para agilizar la solución de controversias en diversos contextos, en particular en los casos de sociedades que habían sufrido conflictos y en las que la comunicación cara a cara para resolver controversias podía resultar difícil. Se informó a la Comisión de que ya se estaban probando mecanismos de solución de controversias en línea asistidos por tecnología o basados en tecnología, así como sistemas de prevención de controversias en línea con apoyo tecnológico, inclusive en comunidades que habían sufrido conflictos. Hasta cierto punto, las tecnologías de vanguardia que combinaban la inteligencia

⁷⁹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/35/17), cap. V, secc. A, párr. 106.*

⁸⁰ Resolución 57/18 de la Asamblea General, anexo.

artificial y la capacidad para aprender y mejorar de forma automática podían servir como sustitutas de árbitros, conciliadores o mediadores al proporcionar opciones para la solución de controversias sin intervención humana o con una intervención mínima. Existían factores como su disponibilidad o accesibilidad en todo momento y su rapidez y asequibilidad que también podían hacer que ganaran popularidad. Así pues, no había que subestimar el potencial de la solución de controversias en línea en ninguna iniciativa internacional destinada a reforzar la eficacia y eficiencia de la solución pacífica de controversias internacionales. Contar con principios y normas armonizados a nivel mundial (por ejemplo, sobre acreditación de proveedores, salvaguardias procesales y solicitudes relacionadas con la constitución de fideicomisos) para utilizar la solución de controversias en línea en diversos contextos (en las relaciones entre empresas, entre empresas y consumidores y entre consumidores, y posiblemente en otros contextos) era fundamental para garantizar la sostenibilidad de la actividad de los proveedores de sistemas de solución de controversias en línea y la eficacia de esos mecanismos. A ese respecto, se destacó la importancia fundamental de la labor del Grupo de Trabajo III (Solución de controversias en línea) de la CNUDMI.

2. Medidas que debe adoptar la Comisión

288. La Comisión dio las gracias a los ponentes por sus declaraciones y se mostró de acuerdo con sus opiniones acerca del papel de la CNUDMI y sus instrumentos en las esferas del arbitraje y la conciliación para promover el estado de derecho y la solución pacífica de controversias internacionales. La Comisión destacó la importante función que podría desempeñar el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia también a ese respecto. Asimismo, observó el carácter cambiante de la solución de controversias en línea y su potencial en relación con la solución de controversias en diversos contextos, en particular en las situaciones posteriores a conflictos.

289. La Comisión recordó las actividades de asistencia técnica realizadas por la Secretaría en la esfera de la solución de controversias, que se reseñan en la nota de la Secretaría sobre cooperación y asistencia técnicas (A/CN.9/775) (véase el párrafo 231 del presente documento). La Comisión también escuchó una declaración sobre los proyectos en Europa sudoriental y el Estado de Palestina relativos a la legislación interna en materia de arbitraje y conciliación, que se ejecutaron en colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. También recordó la misión de asistencia técnica al Iraq que se llevó a cabo en relación con la adopción de la Convención de Nueva York y en la que se contó con la cooperación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La Comisión recordó sus deliberaciones acerca del papel de la guía sobre la Convención de Nueva York de 1958 en la facilitación de la comprensión del texto de la Convención, su cumplimiento eficaz, su interpretación uniforme y su aplicación (véanse los párrafos 134 a 140 del presente documento). A ese respecto, la Comisión observó con aprecio que la Agencia Alemana de Cooperación Internacional había expresado su deseo de prestar apoyo en la preparación de la guía sobre la Convención de Nueva York de 1958, importante instrumento en las actividades de asistencia técnica realizadas en la esfera de la solución de controversias.

290. La Comisión puso de relieve la importancia de las actividades de asistencia técnica de su secretaría para fortalecer el estado de derecho y pidió una colaboración

y una cooperación más estrechas tanto en el sistema de las Naciones Unidas como con entidades interesadas de fuera del sistema, a fin de lograr un mayor uso de las normas preparadas por la CNUDMI. La Comisión reiteró que el papel de los Estados a ese respecto también debía crecer considerablemente.

291. La Comisión recordó que la Asamblea General, en el párrafo 17 de su resolución 67/97, había decidido invitar a los Estados Miembros a que, en el debate de la Sexta Comisión que tendría lugar en 2014 en el marco del tema del programa de la Asamblea titulado “El estado de derecho en los planos nacional e internacional”, se centraran en el subtema “Puesta en común de las prácticas nacionales de los Estados para el fortalecimiento del estado de derecho mediante el acceso a la justicia”. La Comisión invitó a que se formularan observaciones y se realizaran estudios sobre ese subtema para que la Comisión los examinara en su 47º período de sesiones, que se celebraría en 2014.

XV. Labor prevista y posible labor futura, entre otras cosas en los ámbitos del arbitraje y la conciliación, el fraude comercial, el comercio electrónico, el régimen de la insolvencia, el derecho contractual internacional, las microfinanzas, la solución de controversias en línea, la contratación pública y el desarrollo de infraestructuras, incluida la colaboración entre el sector público y el sector privado, y las garantías reales

292. La Comisión recordó que en su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, había solicitado a la Secretaría que preparara una nota sobre la planificación estratégica para examinarla en su 45º período de sesiones, que contuviera posibles opciones de labor futura de la Comisión y una evaluación de sus consecuencias financieras⁸¹. También recordó que había convenido en dar más orientación sobre el rumbo estratégico de la CNUDMI en su período de sesiones en curso, y había pedido a la Secretaría que reservara suficiente tiempo en el 46º período de sesiones que se estaba celebrando para mantener deliberaciones a fondo sobre el tema⁸².

293. La Comisión examinó la nota de la Secretaría sobre la labor prevista y posible labor futura (A/CN.9/774), que complementaba la nota de la Secretaría sobre un rumbo estratégico para la CNUDMI (A/CN.9/752 y Add.1), que se había preparado en respuesta a la solicitud formulada en el 44º período de sesiones a la que se hace referencia en el párrafo anterior. Se señalaron a la atención de la Comisión los informes y textos mencionados en esos documentos. Recibieron amplio apoyo tanto el enfoque como los puntos esenciales expuestos en los documentos A/CN.9/774 y A/CN.9/752 y Add.1.

294. La Comisión analizó algunas cuestiones generales que podrían ser pertinentes para planificar su labor futura y establecer las correspondiente prioridades, incluidas tanto la labor legislativa como las demás actividades de apoyo a la aprobación y el

⁸¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 343.*

⁸² *Ibid., sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 231.*

uso de textos de la CNUDMI descritas en el párrafo 12 del documento A/CN.9/774. Recalcó la importancia de adoptar un enfoque estratégico en la asignación de los escasos recursos de que disponía la CNUDMI, en el contexto de su mandato de modernizar y armonizar el derecho mercantil internacional, y a la luz del número cada vez mayor de temas que se remitían a la CNUDMI para su examen.

295. La Comisión recordó algunas cuestiones estratégicas que se habían planteado en su 45º período de sesiones, a saber:

a) La determinación de las esferas temáticas que debían considerarse de máxima prioridad, en relación con el papel y la importancia de la CNUDMI;

b) La sostenibilidad del método actual, es decir, el hecho de que se diera más importancia a las negociaciones oficiales que a las oficiosas al elaborar textos, habida cuenta de los recursos de que se disponía;

c) El logro de un equilibrio óptimo entre las diversas actividades de la CNUDMI, habida cuenta de los recursos de que se disponía;

d) La movilización de recursos suplementarios y la cuestión de si la CNUDMI debería solicitar recursos externos para desempeñar sus funciones, por ejemplo, mediante actividades conjuntas y la cooperación con otros órganos⁸³.

296. En cuanto a las esferas temáticas que debían considerarse de máxima prioridad, la Comisión observó que al establecer prioridades debían tenerse en cuenta tanto la importancia como la urgencia y recordó las diversas cuestiones que había expuesto anteriormente y a las que se hacía referencia en la sección IV.B del documento A/CN.9/774 (“Establecimiento de prioridades con respecto a las esferas temáticas”).

297. La Comisión puso de relieve la importancia de preparar textos legislativos sobre temas respecto de los cuales era probable que pudiera lograrse un consenso, hubiera una necesidad económica (en el sentido en que se utilizaba esa expresión en el documento A/CN.9/774) y existiera la probabilidad de preparar un texto legislativo que redundara en provecho del desarrollo del derecho mercantil internacional. Se recalcó que el factor principal por el que se debía guiar la Comisión al decidir si abordar un tema debía ser la medida en que un posible texto legislativo fomentaría el desarrollo del derecho mercantil internacional, tal como se había expresado en el mandato que la Asamblea General había encomendado a la CNUDMI. Algunas delegaciones pusieron de relieve que al evaluar la prioridad que debía asignarse a los temas debía tenerse en cuenta el fomento del desarrollo económico y social sostenibles y el estado de derecho, mientras que otras afirmaron que ese apoyo sería un efecto deseable de la armonización y modernización del derecho mercantil internacional en sí mismo.

298. La Comisión escuchó una descripción de determinadas cuestiones expuestas en una propuesta presentada por los Estados Unidos, que figuraba en la sección II del documento A/CN.9/789. En cuanto a las cuestiones planteadas en la sección II de ese documento (en la subsección titulada “Sostenibilidad del método actual”), algunos Estados consideraron adecuado el enfoque que se describía basado en proyectos para la denominación de los grupos de trabajo. Otros expresaron la opinión, que posteriormente prevaleció, de que la flexibilidad que permitiría un

⁸³ *Ibid.*, párr. 229.

enfoque basado en proyectos había existido desde la decisión, adoptada en 2003, de aumentar el número de grupos de trabajo de 3 a 6. Se reconoció que la asignación de tiempo de reuniones a los grupos de trabajo también podía hacerse con más flexibilidad, en lugar de asignarse automáticamente dos semanas anuales a cada tema.

299. Se expresó preocupación en el sentido de que, si la Comisión establecía grupos de trabajo semipermanentes o permanentes cuyos mandatos y atribuciones no se revisaran de forma periódica podría ocurrir que, para dar paso a otros temas, se excluyeran algunos que tal vez la Comisión considerara que debían ser objeto de su labor con carácter prioritario. Sin embargo, se acordó que debía reconocerse y apoyarse la pericia de los grupos de trabajo como medio de sustentar la alta calidad de los textos de la CNUDMI y su pertinencia.

300. La Comisión puso de relieve que la labor de elaboración de textos de la CNUDMI se debía emprender, de modo natural, por conducto del proceso de los grupos de trabajo. A ese respecto, la Comisión recordó el vínculo existente entre ese proceso oficial de negociación y la aplicabilidad universal (y por tanto, también la aceptación) de los textos de la CNUDMI, la importancia de la transparencia que otorgaba ese proceso, y la necesidad de continuar con los métodos de trabajo inclusivos de la CNUDMI. También se convino en que el multilingüismo de los métodos de trabajo de la Comisión constituía un apoyo clave a su labor y debía continuarse con él, incluso teniendo en cuenta la cantidad de recursos que requería.

301. La Comisión convino en que había situaciones excepcionales en las que serían adecuados unos métodos de trabajo más oficiosos para la elaboración de textos legislativos, por ejemplo, en el caso de los aspectos extremadamente técnicos de un tema, y para solucionar cuestiones de redacción cuando un texto estuviera casi finalizado. Se sugirió que, en ese último caso, los métodos de trabajo podrían acelerarse recurriendo a expertos y relatores especiales, a fin de facilitar la preparación final de un texto para presentarlo a la Comisión con miras a su aprobación. Se hizo hincapié en la importancia de la transparencia y el carácter inclusivo, y de evitar la preponderancia de determinados grupos especializados e intereses durante la aplicación de métodos de trabajo oficiosos. Se convino en que se debía dar a la Secretaría flexibilidad para organizar actividades oficiosas según las necesidades de cada esfera temática. La Comisión destacó, no obstante, que la elaboración de textos legislativos de manera oficiosa debía tener límites, y que todos los textos legislativos debían someterse al examen de la Comisión antes de su aprobación. Además, se observó que la labor de preparación previa a encomendar un tema a un grupo de trabajo era tanto adecuada como necesaria, por ejemplo, mediante estudios realizados por la Secretaría, la celebración de coloquios y la asistencia de expertos externos de distintas tradiciones y afiliaciones jurídicas. La Comisión recordó declaraciones anteriores a ese respecto, citadas en el apartado “Temas a los que debería otorgarse la máxima prioridad”, de la sección II del documento A/CN.9/789⁸⁴, en el sentido de que, como norma, un tema no se remitiría a un grupo de trabajo antes de que la Secretaría hubiera realizado un estudio al respecto.

⁸⁴ Véase, por ejemplo, *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17* (A/33/17), párrs. 67 y 68; y una nota de la Secretaría relativa al reglamento y los métodos de trabajo de la CNUDMI (A/CN.9/638, párr. 20).

302. También se planteó la cuestión de la naturaleza de un texto legislativo. Se sugirió que las negociaciones oficiales se limitaran a la preparación de textos vinculantes (como las convenciones) y documentos normativos (como las leyes modelo), y se indicó que la preparación oficiosa de textos legislativos sería apropiada para las guías legislativas y otras modalidades de orientación. Otro punto de vista, que posteriormente prevaleció, fue que se necesitaba un enfoque más flexible, tanto porque no siempre existía una clara línea divisoria entre los textos vinculantes y los de otro tipo, como porque, tal vez, solo durante las negociaciones oficiales se apreciaría claramente qué tipo de texto sería más apropiado. No obstante, se convino en que el mandato de un grupo de trabajo debía ser preciso, reflejar el grado de madurez de la cuestión y establecer claramente el alcance de la labor que habría de emprenderse, incluida la naturaleza prevista del texto legislativo, si procediera.

303. Teniendo presente la escasez de recursos disponibles para la CNUDMI, y en particular el limitado tiempo para conferencias con que contaba (14 semanas por año en el período 2012-2013, incluido cada uno de sus períodos de sesiones), la Comisión acordó evaluar si la elaboración de un determinado tema desde el punto de vista legislativo debía o no confiarse a un grupo de trabajo sobre la base de cuatro pruebas, la primera de las cuales era si quedaba clara la posibilidad de que el tema se aviniera a la armonización y a la elaboración por consenso de un texto legislativo. En ese sentido, recordando que la CNUDMI era una organización de alcance mundial y no regional, se convino en que tal evaluación requeriría la posibilidad de una armonización internacional y no meramente regional.

304. La segunda prueba consistía en determinar si eran suficientemente claros el alcance de un futuro texto y las cuestiones normativas que serían objeto de deliberación. La tercera prueba era si existía o no suficiente probabilidad de que un texto legislativo sobre la cuestión contribuyera a la modernización, armonización o unificación del derecho mercantil internacional. La cuarta prueba era que, en general, no debía emprenderse la elaboración de un texto legislativo si con ello se duplicaba la labor legislativa sobre temas de que se ocupaban otros órganos internacionales o intergubernamentales, y esa labor preparatoria para determinar otras esferas de posible duplicación debía iniciarse antes de remitir el tema a un grupo de trabajo.

305. La Comisión convino en que normalmente evaluaría temas para su examen y la posible elaboración de textos legislativos con una frecuencia anual, pero que sería apropiado establecer alguna planificación indicativa a más largo plazo a fin de comprender lo que se esperaba que la Comisión abordara dentro de un período de tres a cinco años. Se citaron como ejemplo los posibles preparativos para un acto de celebración del 35° aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa en 2015 (véase el párrafo 315 del presente documento). Se recordó la importancia de dar a la Secretaría una flexibilidad apropiada para esa planificación.

306. La Comisión observó que también tendría presente la importancia de evaluar las funciones y la pertinencia de las actividades de la CNUDMI en el marco más amplio de la agenda de las Naciones Unidas y las prioridades de las comunidades de donantes y los gobiernos nacionales. Si bien se expresó un amplio apoyo al uso de un enfoque armonizado de las cuestiones pertinentes con esos órganos, hubo opiniones divergentes en cuanto a las ventajas de adoptar las prioridades de otros

organismos, y se acordó que la cooperación en esa esfera debía acometerse atendiendo a las características de cada caso.

307. La Comisión examinó también el equilibrio entre sus actividades relativas a la elaboración de textos legislativos y aquellas emprendidas en apoyo de esos textos. Con respecto a la asistencia técnica, y observando la creciente demanda de la participación de la Secretaría en esas actividades, según se indica en la nota de la Secretaría sobre cooperación y asistencia técnicas (A/CN.9/775) (véase el párrafo 231 del presente documento), la Comisión subrayó la importancia de esa asistencia para asegurar la aplicación efectiva de los textos de la CNUDMI. Se sugirió que un elemento destacado de la asistencia técnica fuera educar a los posibles usuarios de los textos sobre las soluciones normativas y las normas que abarcaban, de modo que pudieran aplicarlos y utilizarlos eficazmente. Se invitó a la Secretaría a considerar métodos para la realización de esa labor de manera acorde con sus recursos, por ejemplo, mediante la coordinación con otros organismos pertinentes comprendidos o no en el sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, se puso de relieve la capacidad limitada de la Secretaría para abocarse a tales actividades, habida cuenta de la necesidad de asegurar que se le proporcionaran suficientes recursos para prestar servicios a los períodos de sesiones de la Comisión y de sus grupos de trabajo y la necesidad de que los Estados desempeñaran un papel de importancia en las actividades de asistencia técnica.

308. En lo tocante a la coordinación y la cooperación con otros organismos de reforma legislativa, la Comisión hizo hincapié en la necesidad de que, en el marco de las actividades en curso, se establecieran vínculos eficaces dentro y fuera de las Naciones Unidas (por ejemplo, con los bancos multilaterales de desarrollo y otras organizaciones internacionales y regionales, en particular la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el UNIDROIT), se determinaran proyectos conjuntos según procediera y se establecieran prioridades con esos organismos sobre la base de los conocimientos especializados con que contara cada uno de ellos. En la nota de la Secretaría sobre las actividades de coordinación (A/CN.9/776) (véase el párrafo 245 del presente documento) se ofrecieron ejemplos de esas actividades de coordinación y cooperación. (Véanse también los párrafos 245 a 256 del presente documento.)

309. Se sugirió examinar la posibilidad de nombrar al Presidente de la Comisión por un período de un año civil y no por la duración del período de sesiones de la Comisión (que comenzaba en el momento de la apertura del período de sesiones y finalizaba inmediatamente antes del período de sesiones siguiente).

310. La Comisión examinó las propuestas relativas a la labor en curso y la labor futura que tenía a la vista teniendo presentes los aspectos citados y acordó que debía asignar tiempo para el examen de la labor futura como tema separado en cada uno de sus períodos de sesiones. A continuación se indican sus conclusiones respecto de las esferas temáticas para la labor legislativa prevista y la posible labor futura, señaladas en el documento A/CN.9/774.

Arbitraje y conciliación

311. La Comisión recordó el resumen de su debate sobre la labor prevista y la labor futura en la esfera del arbitraje y la conciliación (véanse los párrafos 127 y 129 a 133 del presente documento) y acordó que las actividades futuras en la esfera de la solución de controversias comerciales señaladas en los párrafos 127

y 129 a 133 debían remitirse al Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación), que celebraría dos períodos de sesiones de una semana de duración en el plazo de un año hasta junio de 2014.

Fraude comercial

312. La Comisión escuchó un informe oral sobre el tema del fraude comercial basado en la información que figuraba en la nota de la Secretaría sobre el fraude comercial (A/CN.9/788). La Comisión recordó que, en su 41º período de sesiones, celebrado en 2008, había solicitado a la Secretaría que publicara los “Indicadores de fraude comercial” (A/CN.9/624 y Add.1 y Add.2), en la forma en que se modificaron posteriormente, texto que en general se había considerado útil⁸⁵, y escuchó que el grupo de expertos convocado a raíz de la propuesta formulada por la Comisión en su anterior período de sesiones, en 2012⁸⁶, debería seguir reuniéndose periódicamente para examinar si los indicadores seguían siendo pertinentes y exactos. Se hizo referencia a los planes de preparar, bajo los auspicios del Grupo básico de expertos sobre delitos relacionados con la identidad de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, legislación modelo sobre el delito relacionado con la identidad, y a una solicitud formulada en ese contexto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el sentido de que coordinara con la CNUDMI la preparación de esa legislación modelo⁸⁷. Observando que no se había propuesto que se preparara un nuevo texto legislativo en ese ámbito, la Comisión acogió con beneplácito la propuesta de que se la mantuviera informada de futuros avances.

Comercio electrónico

313. La Comisión recordó el resumen de sus deliberaciones sobre la labor prevista y la labor futura en la esfera del comercio electrónico (párrafos 223 a 230 del presente documento) y convino en que la labor de preparación de un texto legislativo sobre los documentos transmisibles electrónicos continuaría en dos períodos de sesiones de una semana de duración que el Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) celebraría en el plazo de un año, hasta junio de 2014, y que en una fecha posterior se examinaría si esa labor se ampliaría a la gestión de datos de identificación personal, la ventanilla electrónica única y el comercio con dispositivos móviles.

Derecho contractual internacional

314. La Comisión escuchó un informe oral sobre derecho contractual internacional. La Comisión recordó las deliberaciones celebradas al respecto en su 45º período de sesiones, celebrado en 2012⁸⁸, que se resumen en el párrafo 11 e) del documento A/CN.9/774, y la propuesta de Suiza mencionada en ese documento, que figura en el documento A/CN.9/758. La Comisión recordó que en ese período de sesiones había

⁸⁵ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1).*

⁸⁶ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 232.

⁸⁷ Véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2013, Suplemento núm. 10 y corrección (E/2013/30 y Corr.1)*, cap. I, secc. B, proyecto de resolución III, párr. 7.

⁸⁸ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17)*, párrs. 127 a 132.

solicitado a la Secretaría que organizara simposios y otras reuniones, incluso a nivel regional y dentro de los recursos disponibles, manteniendo una estrecha colaboración con el UNIDROIT, con miras a reunir más información para ayudar a la Comisión a evaluar la conveniencia y viabilidad de emprender una labor futura en el ámbito del derecho general de los contratos en un futuro período de sesiones, incluida la posible necesidad de complementar los instrumentos existentes en esa esfera. La Secretaría señaló que, si bien no había podido organizar todas las actividades solicitadas debido a la falta de recursos, había copatrocinado un simposio titulado “Evaluación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa y otras iniciativas internacionales para unificar el derecho contractual internacional” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Villanova (Estados Unidos) en enero de 2013; había celebrado una reunión de expertos en derecho contractual en el Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico en febrero de 2013; y había incluido los documentos pertinentes en la bibliografía que figuraba en su sitio web. Se señaló que la Secretaría seguiría examinando la situación y que informaría a la Comisión según procediera.

315. A la luz de las deliberaciones, y habiendo escuchado una ponencia sobre el tema, expuesto en el documento A/CN.9/789, la Comisión también solicitó a la Secretaría que comenzara a planificar un coloquio con motivo del 35º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa, que tendría lugar en una fecha posterior al 47º período de sesiones de la Comisión, en 2014. La Comisión convino en que el coloquio podía incluir un estudio amplio de la Convención; abarcar algunas de las cuestiones que se habían planteado en una propuesta anterior formulada en su 45º período de sesiones (A/CN.9/758)⁸⁹, así como otras novedades acontecidas en esa esfera (como los Principios del UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales); y estudiar la necesidad de continuar la labor en ese ámbito.

Microfinanzas y constitución de microempresas y pequeñas y medianas empresas

316. La Comisión escuchó un resumen de la labor realizada por la Secretaría en la esfera de las microfinanzas y la constitución de microempresas y pequeñas y medianas empresas, y los resultados del coloquio celebrado sobre ese tema los días 16 a 18 de enero de 2013, en cumplimiento de la solicitud formulada por la Comisión en su 45º período de sesiones, celebrado en 2012⁹⁰.

317. La Comisión tomó nota del amplio consenso entre los participantes en el coloquio, que recomendaron que se encargara a un grupo de trabajo de la CNUDMI la labor de tratar los aspectos jurídicos de la creación de un entorno jurídico propicio para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Los participantes determinaron cinco esferas amplias en las que la Comisión podía ofrecer orientación, la cual se estructuraría con arreglo al ciclo comercial de esas empresas. El punto de partida serían unas pautas para establecer procedimientos simplificados de puesta en marcha y funcionamiento de empresas. Entre los temas que se tratarían posteriormente figuraban los siguientes: a) un sistema de solución de controversias entre prestatarios y prestamistas, incluso teniendo en cuenta las posibilidades de utilizar mecanismos de solución de controversias en línea;

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, párr. 126.

b) el acceso efectivo a servicios financieros para microempresas y pequeñas y medianas empresas, incluido el examen de la posibilidad de ampliar el alcance de los instrumentos existentes de la CNUDMI relativas al comercio electrónico y las transferencias internacionales de crédito de modo que abarcaran los sistemas de pago mediante dispositivos móviles; c) orientaciones sobre el modo de garantizar el acceso al crédito en las que se abordaran cuestiones como la transparencia en los préstamos y la ejecución de todo tipo de operaciones de préstamo; y d) la insolvencia de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, prestando especial atención a los procedimientos acelerados y las opciones de rescate comercial, a fin de elaborar alternativas viables a los procedimientos formales de insolvencia que se ajustaran tanto a las características fundamentales de un sistema eficaz de insolvencia como a las necesidades de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Se dijo que los instrumentos existentes de la CNUDMI y las orientaciones ya elaboradas por las organizaciones internacionales constituían una base adecuada para la labor en esos ámbitos. En cuanto a la forma que podrían adoptar sus orientaciones, se informó a la Comisión de que un instrumento flexible, como una guía legislativa o una ley modelo con arreglo a los temas, contribuiría a armonizar los esfuerzos en ese sector y a impulsar reformas que alentarían en mayor medida la participación de las microempresas en la economía.

318. La Comisión escuchó también una propuesta del Gobierno de Colombia (A/CN.9/790) de que la Comisión diera un nuevo mandato para establecer un grupo de trabajo que se centrara en el ciclo de vida de las empresas, en particular de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. El grupo de trabajo debería comenzar por las medidas para facilitar la constitución y el registro simplificados de sociedades mercantiles y después continuar su labor con otros asuntos, como los examinados en el coloquio de 2013, necesarios para el establecimiento de un entorno jurídico propicio para ese tipo de actividades mercantiles. La propuesta recibió amplio apoyo.

319. Se indicó que en muchos países, tanto en desarrollo como desarrollados, la proporción del ingreso nacional y el empleo correspondiente al sector no estructurado era importante. Sin embargo, las actividades no estructuradas podían perpetuar el incumplimiento de la ley y dificultar el fortalecimiento del estado de derecho. Podían hacer crecer el riesgo de impago de impuestos, aumentar la corrupción y crear un entorno negativo para las inversiones extranjeras y el comercio exterior. Varias delegaciones indicaron que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas necesitaban una base jurídica sobre la que realizar actividades comerciales a nivel internacional y que hacía falta una armonización mayor en lo que se refería a la creación de un entorno jurídico propicio para esas empresas, pues se consideraba que ello contribuiría a aumentar el comercio transfronterizo a nivel internacional y regional.

320. Se expresaron opiniones sobre si en el caso en cuestión se reunían los criterios necesarios para la asignación de un asunto a un grupo de trabajo (véanse los párrafos 303 y 304 del presente documento). Se planteó si determinados temas, como la insolvencia, la solución de controversias y las operaciones garantizadas, relacionados con asuntos de los que ya se ocupaban otros grupos de trabajo, los podían examinar mejor esos grupos de trabajo en lugar de uno nuevo. Algunas delegaciones cuestionaron que el asunto se hubiera estudiado lo suficiente como para que lo examinara un grupo de trabajo y subrayaron que la Secretaría tenía que

realizar el trabajo de base oportuno antes de que se celebrara la primera reunión del grupo.

321. Tras deliberar, la Comisión decidió que se debía añadir a su programa de trabajo la cuestión relativa al derecho mercantil internacional destinado a reducir los obstáculos jurídicos que afectaban a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en todo su ciclo de vida, sobre todo a las de los países en desarrollo. También convino en que al iniciar ese trabajo se debía prestar especial atención a las cuestiones jurídicas relacionadas con la simplificación de la constitución de sociedades, y que la Secretaría debía preparar documentación como requisito para convocar sin tardanza el período de sesiones de un grupo de trabajo. Asimismo, la Comisión acordó que la Secretaría incluiría lo siguiente en su documentación preparatoria para el grupo de trabajo: a) información empírica que demostrara cómo influía ese trabajo en el desarrollo sostenible y la financiación inclusiva y b) información sobre cómo ese trabajo complementaba el de otras organizaciones internacionales e intergubernamentales -de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas- que tenían un mandato relacionado con esas esferas.

322. La Comisión también decidió dejar de utilizar el término “microfinanzas” para hacer referencia al nuevo tema que se asignaría a un grupo de trabajo, concretamente, al Grupo de Trabajo I.

Solución de controversias en línea

323. La Comisión recordó el resumen de su debate sobre la labor prevista y la labor futura en la esfera de la solución de controversias en línea (véanse los párrafos 218 a 222 del presente documento) y convino en que, por consiguiente, la labor relacionada con la solución de controversias en línea continuaría en dos períodos de sesiones del Grupo de Trabajo III, de una semana de duración cada uno, hasta junio de 2014.

Insolvencia

324. La Comisión recordó el resumen de sus deliberaciones sobre la labor prevista y la labor futura en el ámbito del régimen de la insolvencia (véanse los párrafos 210 a 213 del presente documento) y observó que el Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia), no solo no había agotado su mandato actual, sino que aún no había logrado determinar cuál sería el modo más indicado de proseguir esa labor.

325. Tras deliberar, la Comisión decidió que el Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) debería celebrar un coloquio en los primeros días del período de sesiones del Grupo de Trabajo que tendría lugar en el segundo semestre de 2013 para determinar el modo de proceder en lo que respectaba a las cuestiones relativas a un grupo de empresas y otras partes de su mandato actual y examinar temas para su posible labor futura, incluidas cuestiones de insolvencia que afectaban específicamente a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Las conclusiones de ese coloquio no serían determinantes, sino que el Grupo de Trabajo las examinaría y evaluaría en los días restantes del período de sesiones y en el contexto de su mandato actual. En 2014 se debería informar a la Comisión de los temas que se podrían tratar en un futuro.

326. En lo que respecta a la insolvencia de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, la Comisión solicitó al Grupo de Trabajo V que en el período de

sesiones que celebraría en la primera mitad de 2014 realizara un examen preliminar de las cuestiones pertinentes, en particular para determinar si la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia⁹¹ proporcionaba soluciones suficientes y adecuadas para esas empresas. De no ser así, se solicitó al Grupo de Trabajo que considerara qué labor adicional y qué posibles resultados de esa labor podrían necesitarse en un futuro para racionalizar y simplificar los procedimientos de insolvencia de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Las conclusiones sobre esas cuestiones relativas a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas deberían exponerse de manera suficientemente detallada en el informe sobre la labor del Grupo de Trabajo que se presentaría a la Comisión en 2014, a fin de que la Comisión pudiera determinar si en un futuro debería proseguir la labor al respecto.

Colaboración entre el sector público y el privado

327. La Comisión escuchó un resumen de los resultados del coloquio que la Secretaría había organizado en mayo de 2013 en cumplimiento de las instrucciones que le había dado la Comisión en su 45º período de sesiones, celebrado en 2012⁹² (el informe del coloquio figura en el documento A/CN.9/779). La Comisión observó que había acuerdo con respecto a la importancia de ese tema para garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de infraestructura y otros fines, a nivel internacional y regional, y para los Estados, independientemente de su grado de desarrollo.

328. En cuanto a las cuatro pruebas mencionadas en los párrafos 303 y 304 del presente documento, la Comisión observó que el asunto se prestaba a la armonización y a la formulación consensuada de un texto legislativo, habida cuenta de la evolución de la situación con respecto a la colaboración entre el sector público y el privado desde la publicación de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada⁹³. La Comisión escuchó también la conclusión establecida en el coloquio acerca de la falta de una norma universalmente aceptada y aceptable sobre la colaboración entre el sector público y el privado.

329. Por lo que se refiere al mandato de la CNUDMI, se recordó que ya se habían preparado textos legislativos al respecto en el marco de la Comisión y se observó que se había tenido presente la labor de otros organismos en esa esfera para evitar la duplicación de tareas. Se señaló que los instrumentos sobre proyectos de infraestructura con financiación privada, si bien fueron reconocidos como amplios y precisos cuando se publicaron, no siempre se utilizaban como fuente preferida al aprobar disposiciones legislativas sobre la colaboración entre el sector público y el privado. Además, se convino en que quizá habría que actualizar y revisar esos instrumentos, dados los cambios ocurridos en el mercado en cuanto a la colaboración entre el sector público y el privado, y se acordaron los principales

⁹¹ Puede consultarse en www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency.html.

⁹² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17)*, párr. 120.

⁹³ *La Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada* (2000) y las *Disposiciones Legales Modelo de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada* (2003) pueden consultarse en www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.

elementos de un texto legislativo acerca de esa colaboración, que se basaban en gran medida en los instrumentos sobre proyectos de infraestructura con financiación privada.

330. No obstante, habida cuenta de las importantes variaciones en cuanto a terminología, alcance y contenido entre los textos de los distintos países, como se señaló en el coloquio, y de algunas divergencias sobre si había que elaborar una ley modelo u otro texto legislativo, se consideró que sería necesario llevar a cabo una labor preparatoria sobre la cuestión en mayor profundidad, para definir el alcance concreto de cualquier mandato, que después desarrollaría un grupo de trabajo. A ese respecto se subrayó que cualquier texto legislativo debía ser elaborado por conducto de un grupo de trabajo y que la labor preparatoria debía llevarse a cabo de manera integradora y transparente, teniendo en cuenta la experiencia de todas las regiones, la necesidad de contar con el sector público y el sector privado en las consultas y el multilingüismo.

331. Se expresó la opinión de que se necesitaban unos recursos mínimos para llevar a cabo la labor preparatoria necesaria, incluidas las consultas con expertos. Tras deliberar, la Comisión decidió que la Secretaría organizaría esa labor preparatoria con estudios y consultas con expertos, y utilizando hasta una semana del tiempo de reuniones anteriormente asignado al Grupo de Trabajo I de aquí a junio de 2014 para celebrar uno o varios coloquios en cooperación con los órganos internacionales y regionales competentes. Posteriormente se prepararía un nuevo informe para presentarlo a la Comisión en su 47º período de sesiones.

Garantías reales

332. La Comisión recordó el resumen de su debate sobre la labor prevista y la labor futura en la esfera de las garantías reales (véanse los párrafos 192 a 194 del presente documento) y decidió que los trabajos destinados a elaborar una ley modelo sobre las operaciones garantizadas proseguirían en dos períodos de sesiones del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales), de una semana de duración cada uno, hasta junio de 2014, y que más adelante se determinaría si durante ellos se abordaría la cuestión de las garantías reales sobre valores no depositados en poder de un intermediario.

XVI. Resoluciones pertinentes de la Asamblea General

333. La Comisión tomó nota de las dos resoluciones de la Asamblea General que se señalan a continuación, aprobadas por recomendación de la Sexta Comisión: resolución 67/89, relativa al informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 45º período de sesiones; y resolución 67/90, relativa a las recomendaciones para ayudar a las instituciones arbitrales y otros órganos interesados en relación con los arbitrajes regidos por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional revisado en 2010. (Véanse los párrafos 270, 276 y 291 del presente documento, en los que se reseña el examen por la Comisión de otras dos resoluciones de la Asamblea General relativas a la labor de la Comisión (resoluciones 67/1 y 67/97).)

XVII. Otros asuntos

A. Derecho a actas resumidas

334. La Comisión recordó que, en su 45° período de sesiones, celebrado en 2012, había decidido, sin renunciar a su derecho a actas resumidas previsto en la resolución 49/221 de la Asamblea General, solicitar que a modo de prueba se siguieran realizando grabaciones digitales, además de actas resumidas, en sus períodos de sesiones 46° y 47°, previstos para 2013 y 2014, tal como se había hecho en el 45° período de sesiones. En ese período de sesiones la Comisión convino en que en su 47° período de sesiones, previsto para 2014, evaluaría la experiencia adquirida con la utilización de grabaciones digitales y, basándose en esa evaluación, adoptaría una decisión sobre la posible sustitución de las actas resumidas por esas grabaciones. La Comisión pidió a la Secretaría que la informara periódicamente de las medidas que se adoptasen en el sistema de las Naciones Unidas para resolver los posibles problemas que entrañara la utilización de grabaciones digitales. Pidió también a la Secretaría que estudiara la posibilidad de realizar esas grabaciones en los períodos de sesiones de los grupos de trabajo de la CNUDMI que lo solicitaran, y que la informara al respecto en su 47° período de sesiones, previsto para 2014⁹⁴.

335. En su período de sesiones en curso, la Comisión escuchó una ponencia sobre las actualizaciones del sistema de grabaciones digitales utilizado en las Naciones Unidas y observó una demostración del sitio web en el que podían consultarse las grabaciones digitales de los períodos de sesiones 45° y 46° de la Comisión. Se explicó que: a) durante la sesión se grababan digitalmente todos los canales de interpretación y el sonido directo; b) se creaba también un archivo electrónico con la lista de oradores; c) tanto las grabaciones como la lista de oradores podían consultarse poco después de la sesión; d) los archivos podían consultarse en el sistema de gestión mundial de reuniones (gMeets), en el caso de la Secretaría, y en el sitio web de la CNUDMI, en el caso del público en general; e) era técnicamente posible realizar búsquedas por fecha o por título de la sesión; y f) se disponía de un manual en línea en el que se explicaban al usuario las principales características del sistema. El sistema de grabación digital que se estaba utilizando ofrecía al usuario dos alternativas: escuchar inmediatamente una intervención concreta, o descargar una sesión completa en formato MP3, en cualquiera de los idiomas a los que hubiese habido interpretación o en el sonido directo de la sala. La Secretaría podía aportar material adicional para complementar los archivos de la sesión y facilitar la búsqueda de los archivos de sonido, por ejemplo, preparando una transcripción de la sesión, cosa que la Secretaría ya realizaba, en inglés y poco después de la sesión, para algunos órganos de las Naciones Unidas gracias a las economías obtenidas por no tener que proporcionar más actas escritas en los seis idiomas oficiales. El propósito de la transcripción era ayudar a localizar la información de interés dentro de la grabación digital. Podía añadirse también cualquier material disponible en formato electrónico, como ponencias o declaraciones escritas.

336. Se explicó que el sistema digital que generaba ficheros de sonido con fines de archivo formaba parte de la plataforma gMeets, y que esa plataforma permitía a

⁹⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 249.*

cualquier órgano intergubernamental que así lo decidiera sustituir o complementar sus actas escritas de las reuniones u obtener las grabaciones de las reuniones si no disponían de esas actas, como sucedía en el caso de los grupos de trabajo de la CNUDMI. Al mismo tiempo, se informó a la Comisión acerca de la resolución 67/237 de la Asamblea General, en la que la Asamblea hizo notar el proyecto piloto puesto en marcha en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, que consistía en utilizar las grabaciones digitales de las reuniones en los seis idiomas oficiales de la Organización como medida para reducir los gastos; puso de relieve que la ampliación de la aplicación de esa medida debería someterse al examen de la Asamblea General, incluso en lo que respectaba a sus repercusiones desde los puntos de vista jurídico, financiero y de los recursos humanos, y cumplir plenamente lo dispuesto en las resoluciones pertinentes de la Asamblea; y solicitó al Secretario General que la informase al respecto y sobre la evaluación de dicho proyecto piloto en su sexagésimo octavo período de sesiones.

337. La Comisión observó que había habido problemas para publicar en su sitio web, a tiempo y en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, las grabaciones digitales correspondientes a su 45° período de sesiones. Se informó a la Comisión de las medidas que se habían adoptado y de otras medidas que cabía adoptar para conseguir que las grabaciones digitales pudieran consultarse inmediatamente en los seis idiomas, cualquiera que fuese el lugar donde se celebrase un período de sesiones.

338. Se plantearon cuestiones acerca de la sostenibilidad del sistema, concretamente en relación con la necesidad de archivar un gran volumen de datos y garantizar que esos datos pudieran seguir utilizándose en el futuro, aunque se produjeran cambios en la tecnología. La Secretaría respondió que se habían adoptado medidas para garantizar la conservación de los datos durante un período prolongado, entre ellas, la utilización de servidores múltiples y de servicios de respaldo en diversos lugares de destino de la Organización para evitar la pérdida de los datos como consecuencia de eventos extraordinarios que pudieran acaecer en alguno de esos lugares, como la tormenta Sandy que azotó Nueva York en 2012.

339. En respuesta a una pregunta acerca de cómo citar las grabaciones digitales en los documentos escritos, se dijo que ya se había elaborado el procedimiento correspondiente: se citaban el orador, el objeto de la declaración, la fecha, la hora y el tema del programa en relación con el cual se había formulado la declaración, y se incluía un hipervínculo que remitía a la grabación digital correspondiente, con lo que el lector del documento podía escuchar inmediatamente la declaración citada. Al mismo tiempo, se hizo hincapié en que no debía darse a las grabaciones digitales la misma consideración que a las actas oficiales de un órgano intergubernamental; se trataba tan solo de una herramienta de archivo. Para que las grabaciones pudieran equipararse a las actas oficiales sería necesario que el órgano competente del sistema de las Naciones Unidas adoptase una decisión al respecto.

340. Hubo expresiones de apoyo a las grabaciones digitales como alternativa viable a las actas resumidas, habida cuenta de sus evidentes ventajas como: a) el ahorro (el sistema de grabaciones digitales era económico y el ahorro que suponía eliminar la producción de actas resumidas era importante); b) la eficiencia (las grabaciones digitales podían consultarse inmediatamente, a diferencia de las actas literales o resumidas, que a veces se publicaban meses, o incluso años, después de la reunión);

c) la exactitud (el registro del sonido de la sala en los archivos digitales constituía una grabación del sonido totalmente auténtica); y d) las consideraciones ambientales.

341. La Comisión expresó su reconocimiento a la Secretaría por la presentación de información actualizada sobre los avances realizados en el sistema de grabaciones digitales. La Comisión acordó que debía continuar el uso de las grabaciones digitales en la CNUDMI a modo de prueba, en paralelo con la redacción de actas resumidas. La Comisión confirmó también el acuerdo de evaluar en su siguiente período de sesiones, previsto para 2014, la experiencia obtenida con la utilización de las grabaciones digitales y, sobre la base de esa evaluación, adoptar una decisión acerca de la posible sustitución de las actas resumidas por grabaciones digitales.

342. La Comisión acordó que, teniendo en cuenta la confirmación de la Secretaría de que podían realizarse fácilmente grabaciones digitales de los períodos de sesiones de los grupos de trabajo de la CNUDMI, dichas grabaciones debían realizarse salvo decisión en contrario. Como la Presidencia había hecho en el período de sesiones en curso, debía recordarse a los grupos de trabajo interesados que las grabaciones digitales de los períodos de sesiones se pondrían a disposición del público. Se daba por sentado que un órgano intergubernamental siempre podría solicitar que no se realizaran grabaciones de sonido durante un período de sesiones concreto y, de esa forma, renunciar a los servicios de grabación digital. Se expresó la opinión de que la Comisión podría decidir en un futuro período de sesiones si las grabaciones digitales de los grupos de trabajo debían ir acompañadas de una transcripción.

B. Programa de pasantías

343. La Comisión recordó los criterios que su secretaría tenía en cuenta a la hora de seleccionar a los candidatos para las pasantías⁹⁵. Se informó a la Comisión de que, desde la presentación del informe oral de la Secretaría a la Comisión en su 45° período de sesiones, celebrado en julio de 2012, habían realizado una pasantía en la secretaría de la CNUDMI 23 nuevos pasantes, 7 de ellos en el Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico. La mayoría de los pasantes procedían de países en desarrollo y países en transición y eran mujeres. Se comunicó a la Comisión que, mientras que durante el período objeto de examen había mejorado la situación con respecto a la disponibilidad de candidatos elegibles y cualificados para las pasantías procedentes de los Estados de América Latina y el Caribe, la Secretaría seguía teniendo dificultades a la hora de encontrar candidatos apropiados de los Estados de África, así como candidatos con conocimientos del idioma árabe.

344. También se informó a la Comisión de que el procedimiento para la selección de pasantes había cambiado desde el 1 de julio de 2013. Hasta entonces, los pasantes se habían seleccionado de entre los candidatos incluidos en una lista que mantenía y gestionaba la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, mientras que a partir de esa fecha los seleccionaba directamente la secretaría de la CNUDMI de entre los candidatos que habían solicitado la correspondiente vacante que se

⁹⁵ *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 329.

publicaba en el portal de desarrollo profesional de las Naciones Unidas (careers.un.org). Se pidió a los Estados y a las organizaciones observadoras que señalaran a la atención de las personas interesadas ese importante cambio en el procedimiento para la selección de pasantes.

C. Evaluación del papel de la Secretaría en la facilitación de la labor de la Comisión

345. La Comisión recordó que en su 40° período de sesiones, celebrado en 2007⁹⁶, se la había informado del presupuesto por programas para el bienio 2008-2009, en el que se mencionaba, entre los logros previstos de la Secretaría, “su contribución a la facilitación de la labor de la CNUDMI”. La medida de cumplimiento de ese logro previsto era el nivel de satisfacción de la CNUDMI con los servicios prestados, que se ponía de manifiesto en la puntuación, asignada conforme a una escala que iba de 1 a 5 (5 era la puntuación más alta)⁹⁷. En ese período de sesiones, la Comisión había acordado proporcionar información al respecto a la Secretaría. Desde entonces y hasta el 45° período de sesiones de la Comisión, celebrado en 2012, la Secretaría había distribuido a los delegados y representantes de los Estados observadores que asistieron a los períodos de sesiones anuales de la CNUDMI, al finalizar el período de sesiones, un cuestionario en el que se les solicitaba que evaluaran la calidad de los servicios prestados por la Secretaría para facilitar la labor de la Comisión. La Comisión observó que la Secretaría no había recibido mucha información en respuesta a esa solicitud; la única respuesta que se había recibido indicaba en general un alto nivel de satisfacción.

346. La Comisión tomó nota también de que durante su 45° período de sesiones, celebrado en 2012, no se había distribuido ese cuestionario; en su lugar, el 22 de marzo de 2013 la Secretaría había enviado a todos los Estados una nota verbal en la que les solicitaba que indicasen, cumplimentando el formulario de evaluación que se adjuntaba, su nivel de satisfacción con los servicios prestados a la CNUDMI por su secretaría desde el inicio de su 45° período de sesiones (celebrado en Nueva York del 25 de junio al 6 de julio de 2012). La fecha límite para presentar la evaluación había sido el 7 de julio de 2013, el día anterior a la apertura del período de sesiones en curso de la Comisión.

347. Se comunicó a la Comisión que la solicitud había dado lugar a un número de respuestas inusualmente elevado (15) y que el nivel de satisfacción con los servicios prestados a la CNUDMI por su secretaría seguía siendo alto (un promedio de 4,8 de un máximo de 5). A la luz del gran número de formularios recibidos durante el año en curso en respuesta a la nota verbal enviada, la Secretaría mantendría la práctica de solicitar la información pertinente a los Estados por medio de una nota verbal que se enviaría en fechas próximas al inicio del período de sesiones anual de la Comisión, como se había hecho el año en curso, e informaría a la Comisión en sus períodos de sesiones anuales acerca de los resultados de la evaluación determinados a partir de las respuestas recibidas.

⁹⁶ *Ibid.*, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17), primera parte, párr. 243.

⁹⁷ A/62/6 (Secc. 8) y Corr.1, cuadro 8.19 d).

XVIII. Lugar y fecha de futuras reuniones

348. La Comisión recordó que en su 36º período de sesiones, celebrado en 2003, había convenido en que: a) sus grupos de trabajo se reunieran normalmente dos veces al año en períodos de sesiones de una semana; b) de ser necesario, podría asignarse tiempo adicional a otro grupo de trabajo, siempre que con ello no se sobrepasara el límite total de 12 semanas anuales de servicios de conferencias para los períodos de sesiones de los seis grupos de trabajo de la Comisión; y c) en caso de que un grupo de trabajo solicitara tiempo suplementario con el que se rebasara el límite de las 12 semanas, la Comisión debería examinar la solicitud y el grupo de trabajo correspondiente debía proporcionar la debida justificación en cuanto a los motivos por los que fuera necesario modificar la estructura de reuniones⁹⁸.

349. La Comisión también recordó que en su 45º período de sesiones, celebrado en 2012, había tomado nota del párrafo 48 de la resolución 66/246 de la Asamblea General sobre cuestiones relativas al proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2012-2013, en la que la Asamblea había decidido aumentar los recursos no relacionados con puestos a fin de suministrar fondos suficientes para la prestación de servicios durante 14 semanas a la Comisión y mantener la modalidad de rotación entre Viena y Nueva York. Habida cuenta de esa decisión, la Comisión observó en ese período de sesiones que el total de 12 semanas anuales de servicios de conferencias se podría seguir asignando a seis grupos de trabajo de la Comisión que se reunieran dos veces al año durante una semana, si los períodos de sesiones anuales de la Comisión no duraran más de dos semanas. De lo contrario, deberían hacerse ajustes en el marco de la asignación actual de 14 semanas para todos los períodos de sesiones de la Comisión y sus grupos de trabajo⁹⁹.

350. En el período de sesiones en curso, la Comisión hizo hincapié en la necesidad de actuar con flexibilidad al asignar tiempo de reuniones (véase el párrafo 298 del presente documento).

A. El 47º período de sesiones de la Comisión

351. Teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, la Comisión aprobó la celebración de su 47º período de sesiones en Nueva York del 7 al 25 de julio de 2014. Se pidió a la Secretaría que considerara la posibilidad de reducir una semana la duración del período de sesiones si las previsiones del volumen de trabajo para el período de sesiones lo justificaran.

B. Períodos de sesiones de los grupos de trabajo

1. Períodos de sesiones de los grupos de trabajo entre los períodos de sesiones 46º y 47º de la Comisión

352. A la luz de las consideraciones antes expuestas, la Comisión aprobó el siguiente calendario para las reuniones de sus grupos de trabajo:

⁹⁸ *Documentos Oficiales de las Naciones Unidas, quincuagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/58/17), párr. 275*

⁹⁹ *Ibid., sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 258.*

a) El Grupo de Trabajo I celebraría su 22º período de sesiones del 23 al 27 de septiembre de 2013 en Viena, y su 23º período de sesiones del 10 al 14 de febrero de 2014 en Nueva York;

b) El Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) celebraría su 59º período de sesiones del 16 al 20 de septiembre de 2013 en Viena, y su 60º período de sesiones del 3 al 7 de febrero de 2014 en Nueva York;

c) El Grupo de Trabajo III (Solución de Controversias en Línea) celebraría su 28º período de sesiones del 18 al 22 de noviembre de 2013 en Viena, y su 29º período de sesiones del 24 al 28 de marzo de 2014 en Nueva York;

d) El Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) celebraría su 48º período de sesiones del 9 al 13 de diciembre de 2013 en Viena, y su 49º período de sesiones del 28 de abril al 2 de mayo de 2014 en Nueva York;

e) El Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) celebraría su 44º período de sesiones del 16 al 20 de diciembre de 2013 en Viena, y su 45º período de sesiones del 21 al 25 de abril de 2014 en Nueva York;

f) El Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) celebraría su 24º período de sesiones del 7 al 11 de octubre o del 2 al 6 de diciembre de 2013 en Viena, y su 25º período de sesiones del 31 de marzo al 4 de abril de 2014 en Nueva York.

353. La Comisión autorizó a la Secretaría a ajustar el calendario de las reuniones de sus grupos de trabajo en función de las necesidades de cada grupo de trabajo y de la necesidad de celebrar coloquios, según lo acordado por la Comisión en su período de sesiones en curso (véanse los párrafos 325 y 331 del presente documento). Se pidió a la Secretaría que anunciara en el sitio web de la CNUDMI el calendario definitivo de las reuniones de los grupos de trabajo una vez que se hubieran confirmado las fechas.

2. Períodos de sesiones de los grupos de trabajo en 2014 tras la celebración del 47º período de sesiones de la Comisión

354. La Comisión tomó nota de que se habían fijado las siguientes fechas para sus reuniones en 2014 tras la celebración de su 47º período de sesiones: a) 8 a 12 de septiembre de 2014 o 20 a 24 de octubre de 2014; b) 22 a 26 de septiembre de 2014; c) 10 a 14 de noviembre de 2014; d) 17 a 21 de noviembre de 2014; e) 8 a 12 de diciembre de 2014; y f) 15 a 19 de diciembre de 2014.

Anexo I

Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Aplicabilidad del Reglamento

1. El Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado (“Reglamento sobre la Transparencia”) se aplicará a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado que establezca la protección de las inversiones o los inversionistas (“el tratado”*) celebrado el 1 de abril de 2014 o después de esa fecha, a menos que las partes en el tratado** hayan acordado otra cosa.

2. Con respecto a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado celebrado antes del 1 de abril de 2014, este Reglamento solamente se aplicará si:

a) las partes en un arbitraje (las “partes litigantes”) convienen en su aplicación respecto de ese arbitraje; o

b) las partes en el tratado o, en el caso de un tratado multilateral, el Estado del demandante y el Estado demandado han convenido en su aplicación después del 1 de abril de 2014 .

Aplicación del Reglamento

3. En todo arbitraje en que sea aplicable el Reglamento sobre la Transparencia de conformidad con un tratado o con un acuerdo concertado por las partes en ese tratado:

a) las partes litigantes no podrán apartarse de este Reglamento, ni mediante acuerdo ni de ningún otro modo, a menos que el tratado se lo permita;

b) el tribunal arbitral, al margen de las facultades discrecionales que le confieren algunas disposiciones de este Reglamento, estará facultado para adaptar los requisitos de cualquiera de sus disposiciones concretas a las circunstancias del caso, tras celebrar consultas con las partes litigantes, si esa adaptación resulta necesaria para que el arbitraje se lleve a cabo de una forma práctica y si es coherente con el objetivo de transparencia de este Reglamento.

Discrecionalidad y autoridad del tribunal arbitral

4. Cuando el Reglamento sobre la Transparencia establezca que el tribunal arbitral tendrá facultades discrecionales, en el ejercicio de tales facultades el tribunal arbitral tendrá en cuenta:

a) El interés público en la transparencia de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado y del procedimiento arbitral en particular, y

b) El interés de las partes litigantes en que la controversia se resuelva de manera justa y eficiente.

5. Este Reglamento no afectará a la autoridad que pueda tener el tribunal arbitral en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI para dirigir el arbitraje de tal forma que se promueva la transparencia, por ejemplo, aceptando escritos presentados por terceros.

6. Ante cualquier conducta, medida u otra acción que tenga el efecto de menoscabar por completo los objetivos de transparencia del presente Reglamento, el tribunal arbitral se asegurará de que prevalezcan dichos objetivos.

Instrumento aplicable en caso de conflicto

7. Siempre que el Reglamento sobre la Transparencia sea aplicable, complementará cualquier otro reglamento de arbitraje aplicable. Cuando exista un conflicto entre el Reglamento sobre la Transparencia y el reglamento de arbitraje aplicable, prevalecerá el Reglamento sobre la Transparencia. Independientemente de lo dispuesto en este Reglamento, cuando exista un conflicto entre el Reglamento sobre la Transparencia y el tratado prevalecerá lo dispuesto en el tratado.

8. Cuando una norma de este Reglamento esté en conflicto con una disposición del derecho aplicable al arbitraje de la que las partes no puedan apartarse, prevalecerá esa disposición.

Aplicación en arbitrajes que no estén sujetos al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI

9. El presente Reglamento podrá aplicarse en arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con otros reglamentos que no sean el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI o en procedimientos *ad hoc*.

Notas de pie de página del artículo 1, párrafo 1:

*A los fines del Reglamento sobre la Transparencia, por “tratado” se entenderá, en sentido amplio, todo tratado bilateral o multilateral que contenga disposiciones sobre la protección de las inversiones o los inversionistas y el derecho de los inversionistas a recurrir al arbitraje contra las partes en el tratado, incluidos los tratados comúnmente denominados acuerdos de libre comercio, acuerdos de integración económica, acuerdos marco o de cooperación en materia de comercio e inversiones o tratados bilaterales de inversión.

** A los fines del Reglamento sobre la Transparencia, toda referencia a una “parte en el tratado” o a un “Estado” incluye, por ejemplo, una organización regional de integración económica que sea parte en el tratado.

Artículo 2. Publicación de información al inicio del procedimiento arbitral

Una vez que el demandado haya recibido la notificación del arbitraje, cada una de las partes litigantes transmitirá sin demora una copia de esta al archivo

mencionado en el artículo 8. Tras haber recibido la notificación del arbitraje del demandado, o tras haber recibido la notificación del arbitraje y el registro de su transmisión al demandado, el archivo procederá sin demora a poner a disposición del público la información relativa al nombre de las partes litigantes, el sector económico afectado y el tratado en virtud del cual se formula la demanda.

Artículo 3. Publicación de documentos

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 7, los documentos siguientes se darán a conocer al público: la notificación del arbitraje; la respuesta a la notificación del arbitraje; el escrito de demanda, el escrito de contestación y toda otra declaración o comunicación escritas de cualquiera de las partes litigantes; una lista de todas las pruebas correspondientes a dichos documentos y a los informes de los peritos y las declaraciones de los testigos, si esa lista ha sido preparada para las actuaciones, pero no las pruebas en sí; todo escrito presentado por partes en el tratado que no son litigantes y por terceros; las transcripciones de las audiencias, cuando se disponga de ellas; y las órdenes procesales, decisiones y laudos del tribunal arbitral.

2. A reserva de lo dispuesto en el artículo 7, los informes de los peritos y las declaraciones de los testigos, excluidas las pruebas correspondientes, se pondrán a disposición del público si así lo pide cualquier persona al tribunal arbitral.

3. A reserva de lo dispuesto en el artículo 7, el tribunal arbitral podrá decidir, por iniciativa propia o a solicitud de cualquier persona, y previa consulta con las partes litigantes, si las pruebas y demás documentos que emita o reciba el tribunal arbitral no incluidos en los párrafos 1 o 2 *supra* se publicarán, y de qué forma. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que se pongan esos documentos a disposición del público en un sitio determinado.

4. Los documentos que se vayan a poner a disposición del público con arreglo a lo establecido en los párrafos 1 y 2 serán comunicados por el tribunal arbitral al archivo mencionado en el artículo 8 lo antes posible, de conformidad con las disposiciones o plazos para la protección de la confidencialidad o de información protegida establecidos en el artículo 7. Los documentos que se vayan a poner a disposición del público con arreglo a lo establecido en el párrafo 3 podrán ser comunicados por el tribunal arbitral al archivo mencionado en el artículo 8 a medida que se disponga de ellos y, cuando proceda, en su forma expurgada de conformidad con el artículo 7. El archivo hará públicos oportunamente todos los documentos en la forma y el idioma en que los haya recibido.

5. Las personas que reciban acceso a documentos con arreglo a lo establecido en el párrafo 3 sufragarán los gastos administrativos que conlleve facilitar el acceso de esas personas a los documentos, como los gastos de fotocopiado o envío de los documentos a esas personas, pero no los gastos que conlleve facilitar el acceso del público a esos documentos por medio del archivo.

Artículo 4. Escritos presentados por terceros

1. Tras consultar con las partes litigantes, el tribunal arbitral podrá permitir que una persona que no sea parte litigante ni sea una parte en el tratado no litigante (“tercero”) presente al tribunal un escrito relativo a cuestiones que sean objeto del litigio.

2. El tercero que desee presentar un escrito lo solicitará al tribunal arbitral e indicará, en una declaración escrita concisa, redactada en uno de los idiomas del arbitraje y ajustada al límite de páginas que haya determinado el tribunal, lo siguiente:

a) Descripción del tercero, indicando, si procede, la organización de que sea miembro y su condición jurídica (por ejemplo, asociación profesional u otra entidad no gubernamental), sus objetivos generales, la índole de sus actividades, y toda entidad matriz (incluida toda entidad que controle directa o indirectamente al tercero);

b) Divulgación de si el tercero tiene o no algún tipo de afiliación, directa o indirecta, con alguna parte litigante;

c) Información sobre todo gobierno, persona u organización que haya prestado al tercero i) ayuda financiera o de otra índole para la preparación del escrito; o ii) ayuda considerable en cualquiera de los dos años anteriores a la solicitud presentada por el tercero con arreglo al presente artículo (por ejemplo, la financiación de aproximadamente el 20% del total de sus operaciones anualmente);

d) Descripción de la índole del interés del tercero en el arbitraje; y

e) Indicación de las cuestiones concretas de hecho y de derecho suscitadas en el arbitraje que el tercero desee tratar en su escrito.

3. Para determinar si permite la presentación de un escrito, el tribunal arbitral tomará en consideración, entre otros factores que considere pertinentes:

a) si el tercero tiene un interés considerable en el procedimiento arbitral; y

b) la medida en que el escrito pueda ayudar al tribunal arbitral a determinar alguna cuestión de hecho o de derecho relativa al procedimiento arbitral, al aportar enfoques, conocimientos particulares o puntos de vista distintos a los de las partes litigantes.

4. El escrito presentado por el tercero deberá:

a) estar fechado y firmado por la persona que lo presente en nombre del tercero;

b) ser conciso y no exceder en ningún caso la extensión autorizada por el tribunal arbitral;

c) enunciar, en términos precisos, la posición del tercero respecto de las cuestiones en litigio; y

d) referirse únicamente a cuestiones en litigio.

5. El tribunal arbitral deberá asegurar que los escritos no perturben ni dificulten innecesariamente el procedimiento arbitral y que no causen ningún perjuicio indebido a ninguna de las partes litigantes.

6. El tribunal arbitral deberá asegurar que se dé a las partes litigantes una oportunidad razonable de formular observaciones acerca de los escritos presentados por el tercero.

Artículo 5. Escritos presentados por partes en el tratado que no sean litigantes

1. El tribunal arbitral permitirá, con arreglo al párrafo 4, que partes en el tratado que no sean litigantes presenten escritos o, tras consultar con las partes litigantes, podrá invitar a partes en el tratado que no sean litigantes a que presenten escritos sobre cuestiones relativas a la interpretación del tratado.

2. El tribunal arbitral, tras celebrar consultas con las partes litigantes, podrá permitir que partes en el tratado que no sean litigantes presenten escritos sobre otras cuestiones que sean objeto del litigio. Para determinar si permite la presentación de tales escritos, el tribunal arbitral tendrá en cuenta, entre otros factores que considere pertinentes, los factores mencionados en el artículo 4, párrafo 3, y, a fin de aportar una mayor certeza, la necesidad de evitar la presentación de escritos en que se apoye la reclamación de un inversionista de modo tal que equivalga a protección diplomática.

3. El tribunal arbitral no sacará conclusión alguna de la falta de escritos o de respuesta ante una invitación formulada con arreglo a lo establecido en los párrafos 1 o 2.

4. El tribunal arbitral asegurará que los escritos presentados no perturben ni dificulten innecesariamente el procedimiento arbitral y no causen ningún perjuicio indebido a ninguna de las partes litigantes.

5. El tribunal arbitral asegurará que se dé a las partes litigantes una oportunidad razonable de hacer observaciones acerca de los escritos presentados por partes en el tratado que no sean litigantes.

Artículo 6. Audiencias

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 6, párrafos 2 y 3, las audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales (“audiencias”) serán públicas.

2. Cuando sea necesario proteger la información confidencial o la integridad del proceso arbitral con arreglo a lo establecido en el artículo 7, el tribunal arbitral adoptará disposiciones para celebrar en privado la parte de la audiencia que deba ser protegida.

3. El tribunal arbitral adoptará disposiciones logísticas para facilitar el acceso del público a las audiencias (incluso, según proceda, organizando la asistencia mediante enlaces de vídeo u otros medios que estime conveniente). No obstante, el tribunal arbitral podrá, tras celebrar consultas con las partes litigantes, decidir que toda la audiencia o parte de ella se celebre en privado cuando resulte necesario por motivos logísticos, por ejemplo cuando debido a las circunstancias no pueda adoptarse ninguna disposición logística viable para permitir el acceso del público a las audiencias.

Artículo 7. Excepciones a la norma de la transparencia

Información confidencial o protegida

1. La información confidencial o protegida, como se define en el párrafo 2 y se determina en cumplimiento de las disposiciones a que se hace referencia en

los párrafos 3 y 4, no se pondrá a disposición del público con arreglo a los artículos 2 a 6.

2. La información confidencial o protegida consiste en:

- a) Información comercial confidencial;
- b) Información que, conforme al tratado, no debe ponerse a disposición del público;
- c) Información que no debe ponerse a disposición del público, en el caso de la información del Estado demandado, con arreglo a la legislación de este, y en el caso de información de otro tipo, con arreglo a cualquier ley o normativa que el tribunal arbitral determine que es aplicable a la divulgación de esa clase de información; o
- d) Información cuya divulgación impidiera hacer cumplir la ley.

3. El tribunal arbitral, tras celebrar consultas con las partes litigantes, adoptará disposiciones para impedir que se ponga información confidencial o protegida a disposición del público, inclusive estableciendo, según proceda:

- a) Plazos para que una parte litigante, una parte en el tratado no litigante o un tercero indique que desea proteger dicha información en los documentos;
- b) Procedimientos para seleccionar y suprimir rápidamente de esos documentos la información confidencial o protegida; y
- c) Procedimientos para celebrar audiencias en privado, en la medida en que ello se prevea en el artículo 6, párrafo 2.

El tribunal arbitral decidirá, previa consulta con las partes litigantes, si determinada información es confidencial o protegida.

4. Si el tribunal arbitral determina que no debe suprimirse información de un documento, o que no debe impedirse que el documento se haga público, cualquier parte litigante, parte en el tratado no litigante o tercero que en forma voluntaria hubiera incorporado el documento al expediente del procedimiento arbitral podrá retirar el documento o una parte de este de dicho expediente.

5. Nada de lo dispuesto en este Reglamento obligará al Estado demandado a poner a disposición del público información cuya divulgación considere contraria a sus intereses de seguridad esenciales.

Integridad del proceso arbitral

6. No se pondrá información a disposición del público con arreglo a los artículos 2 a 6 cuando esa información, si se pusiera a disposición del público, pudiera poner en peligro la integridad del proceso arbitral conforme a lo dispuesto en el párrafo 7.

7. El tribunal podrá, por iniciativa propia o a solicitud de una parte litigante, previa consulta con las partes litigantes cuando sea viable, adoptar las medidas adecuadas para impedir o demorar la publicación de información cuando tal publicación pueda poner en peligro la integridad del proceso arbitral porque pueda dificultar la reunión o presentación de pruebas, dar lugar a la intimidación de

testigos, abogados de las partes litigantes o miembros del tribunal arbitral, o en circunstancias excepcionales comparables.

Artículo 8. Archivo de la información publicada

El archivo de la información publicada conforme al Reglamento sobre la Transparencia será el Secretario General de las Naciones Unidas o una institución nombrada por la CNUDMI.

Anexo II

Modificación del artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI

Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013)

Ámbito de aplicación

Artículo 1

4. En el caso de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas, el presente Reglamento incluye el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia, a reserva de lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento sobre la Transparencia.

Anexo III

Lista de documentos presentados a la Comisión en su 46° período de sesiones

<i>Signatura</i>	<i>Título o descripción</i>
A/CN.9/759	Programa provisional con anotaciones y calendario de reuniones del 46° período de sesiones
A/CN.9/760	Informe del Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) sobre la labor de su 57° período de sesiones
A/CN.9/761	Informe del Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) sobre la labor realizada en su 46° período de sesiones
A/CN.9/762	Informe del Grupo de Trabajo III (Solución de Controversias en Línea) sobre la labor de su 26° período de sesiones
A/CN.9/763	Informe del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) sobre la labor realizada en su 42° período de sesiones
A/CN.9/764	Informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 22° período de sesiones
A/CN.9/765	Informe del Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) sobre la labor realizada en su 58° período de sesiones
A/CN.9/766	Informe del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) sobre la labor realizada en su 43° período de sesiones
A/CN.9/767	Informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 23° período de sesiones
A/CN.9/768	Informe del Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) sobre la labor realizada en su 47° período de sesiones
A/CN.9/769	Informe del Grupo de Trabajo III (Solución de Controversias en Línea) sobre la labor de su 27° período de sesiones
A/CN.9/770	Directrices para la promulgación de un reglamento de la contratación pública de conformidad con el artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública
A/CN.9/771	Glosario de términos relacionados con la contratación pública utilizados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública
A/CN.9/772	Nota de la Secretaría en que figura una bibliografía de obras recientemente publicadas relativas a la labor de la CNUDMI
A/CN.9/773	Nota de la Secretaría sobre la situación actual de las convenciones y leyes modelo
A/CN.9/774	Nota de la Secretaría sobre la labor prevista y la posible labor futura

<i>Signatura</i>	<i>Título o descripción</i>
A/CN.9/775	Nota de la Secretaría sobre cooperación y asistencia técnicas
A/CN.9/776	Nota de la Secretaría sobre las actividades de coordinación
A/CN.9/777	Nota de la Secretaría sobre el fomento de los modos necesarios para asegurar una interpretación y una aplicación uniformes de los textos jurídicos de la CNUDMI
A/CN.9/778	Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial
A/CN.9/779	Nota de la Secretaría sobre la posible labor futura en la esfera de la colaboración entre el sector público y el privado: informe del coloquio de la CNUDMI sobre la colaboración entre el sector público y el privado
A/CN.9/780	Microfinanciación: creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas
A/CN.9/781 y Add.1 y 2	Proyecto de Guía de la CNUDMI sobre la creación de un registro de garantías reales
A/CN.9/782	Documento de debate para el Coloquio Internacional sobre la colaboración entre el sector público y el sector privado
A/CN.9/783	Solución de controversias comerciales: proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado
A/CN.9/784	Solución de controversias comerciales: aplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia de la CNUDMI a la solución de controversias surgidas en el marco de tratados de inversión ya existentes
A/CN.9/785	Solución de controversias comerciales: posible labor futura en materia de solución de controversias comerciales
A/CN.9/786	Solución de controversias comerciales: guía de la CNUDMI relativa a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958): extracto de la guía sobre el artículo VII
A/CN.9/787 y Add.1 a 3 y Add.1/Corr.1	Solución de controversias comerciales: proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado: compilación de las observaciones de los gobiernos
A/CN.9/788	Nota de la Secretaría sobre el fraude comercial
A/CN.9/789	Propuesta del Gobierno de los Estados Unidos relativa a la labor futura de la CNUDMI: tema 16 del programa provisional
A/CN.9/790	Propuesta del Gobierno de Colombia

<i>Signatura</i>	<i>Título o descripción</i>
A/CN.9/791	Solución de controversias comerciales: proyecto de Reglamento sobre la Transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado: archivo de la información publicada en virtud del artículo 8 del proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado
A/CN.9/792 y Add.1 a 3	Revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo y proyecto de cuarta parte de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia: recopilación de las observaciones de los gobiernos

**B. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD): pasajes del informe de la Junta de Comercio
y Desarrollo sobre su 60º período de sesiones
(TD/B/60/11)**

**Desarrollo progresivo del derecho mercantil internacional: 46º informe anual de
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional**

En su 1107ª sesión plenaria, la Junta tomó nota del informe anual de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en su 46º período de sesiones (A/68/17), celebrado en Nueva York, Estados Unidos de América, del 8 al 26 de julio de 2013).

C. Asamblea General: Informe de la Sexta Comisión relativo al informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 46° período de sesiones (A/68/462)

[Original: inglés]

Relator: Sr. Tofiq **Musayev** (Azerbaiyán)

I. Introducción

1. En su segunda sesión plenaria, celebrada el 20 de septiembre de 2013, la Asamblea General, por recomendación de la Mesa, decidió incluir en el programa de su sexagésimo octavo período de sesiones el tema titulado “Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 46° período de sesiones” y asignarlo a la Sexta Comisión.
2. La Sexta Comisión consideró el tema en sus sesiones 9ª, 10ª, 28ª y 29ª, celebradas los días 14 y 16 de octubre y 8 y 15 de noviembre de 2013. Las opiniones de los representantes que hicieron uso de la palabra durante el examen del tema por la Comisión constan en las actas resumidas correspondientes (A/C.6/68/SR.9, 10, 28 y 29).
3. Para su examen del tema, la Comisión tuvo ante sí el informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 46° período de sesiones (A/68/17).
4. En la 9ª sesión, celebrada el 14 de octubre, el Presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en su 46° período de sesiones presentó el informe de dicha Comisión sobre la labor realizada en ese período de sesiones.

II. Examen de las propuestas

A. Proyecto de resolución A/C.6/68/L.9

5. En la 28ª sesión, celebrada el 8 de noviembre, el representante de Austria, en nombre de la Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, el Brasil, Bulgaria, Croacia, Chile, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, los Estados Unidos de América, Estonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, la Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, el Gabón, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, la India, Irlanda, Israel, Italia, el Japón, Jordania, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Mauricio, México, Montenegro, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa, la República de Corea, Rumania, Serbia, Singapur, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Turquía, Ucrania, Uganda y Venezuela (República Bolivariana de), presentó un proyecto de resolución titulado “Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 46° período de sesiones” (A/C.6/68/L.9).

6. En la 29ª sesión, celebrada el 15 de noviembre, Alemania, Dinamarca y Malta se sumaron a los patrocinadores del proyecto de resolución.

7. En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución A/C.6/68/L.9 sin someterlo a votación (véase el párr. 14, proyecto de resolución I).

B. Proyecto de resolución A/C.6/68/L.10

8. En la 28ª sesión, celebrada el 8 de noviembre, el representante de Austria, en nombre de la Mesa, presentó un proyecto de resolución titulado “Revisión de la Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza y cuarta parte de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia” (A/C.6/68/L.10).

9. En su 29ª sesión, celebrada el 15 de noviembre, la Comisión aprobó el proyecto de resolución A/C.6/68/L.10 sin someterlo a votación (véase el párr. 14, proyecto de resolución II).

C. Proyecto de resolución A/C.6/68/L.11

10. En la 28ª sesión, celebrada el 8 de noviembre, el representante de Austria, en nombre de la Mesa, presentó un proyecto de resolución titulado “Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales” (A/C.6/68/L.11).

11. En la 29ª sesión, celebrada el 15 de noviembre, la Comisión aprobó el proyecto de resolución A/C.6/68/L.11 sin someterlo a votación (véase el párr. 14, proyecto de resolución III).

D. Proyecto de resolución A/C.6/68/L.12

12. En la 28ª sesión, celebrada el 8 de noviembre, el representante de Austria, en nombre de la Mesa, presentó un proyecto de resolución titulado “Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado y el Reglamento de Arbitraje (según el texto revisado de 2010, con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013)” (A/C.6/68/L.12).

13. En la 29ª sesión, celebrada el 15 de noviembre, la Comisión aprobó el proyecto de resolución A/C.6/68/L.12 sin someterlo a votación (véase el párr. 14, proyecto de resolución IV).

III. Recomendaciones de la Sexta Comisión

14. La Sexta Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe los siguientes proyectos de resolución:

Proyecto de resolución I
Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 46º período
de sesiones

La Asamblea General,

Recordando su resolución 2205 (XXI), de 17 de diciembre de 1966, en la que estableció la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y le confirió el mandato de promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional y, a ese respecto, tener presentes los intereses de todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo, en la evolución general del comercio internacional,

Reafirmando su convencimiento de que la modernización y armonización progresivas del derecho mercantil internacional, al reducir o eliminar los obstáculos jurídicos que se oponen al flujo del comercio internacional, especialmente los que afectan a los países en desarrollo, contribuirían de modo significativo a la cooperación económica universal entre todos los Estados sobre una base de igualdad, equidad, interés común y respeto del estado de derecho, así como a la eliminación de la discriminación en el comercio internacional y, por consiguiente, a la paz, la estabilidad y el bienestar de todos los pueblos,

Habiendo examinado el informe de la Comisión¹,

Reiterando su preocupación por el hecho de que las actividades realizadas por otros órganos en el ámbito del derecho mercantil internacional sin coordinación suficiente con la Comisión puedan dar lugar a una duplicación no deseable del trabajo y no se ajusten al objetivo de fomentar la eficiencia, uniformidad y coherencia en la unificación y armonización del derecho mercantil internacional,

Reafirmando el mandato conferido a la Comisión para que, en su calidad de órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional, coordine las actividades jurídicas en la materia, en particular con el fin de evitar la duplicación del trabajo, especialmente entre las organizaciones que elaboran normas de comercio internacional, y fomentar la eficiencia, uniformidad y coherencia en la modernización y armonización del derecho mercantil internacional y, por conducto de su secretaría, continúe manteniendo una estrecha cooperación con otros órganos y organizaciones internacionales que se ocupan del derecho mercantil internacional, incluidas las organizaciones regionales,

1. *Toma nota con aprecio* del informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional¹;

2. *Encomia* a la Comisión por haber finalizado y aprobado el Reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado², el Reglamento de Arbitraje (según el texto revisado de 2010, con el

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17).*

² *Ibid.*, cap. III y anexo I.

nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013)³, la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales⁴, la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza⁵, la cuarta parte de la *Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia*, relativa a las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia⁶, las directrices para la promulgación de un reglamento de la contratación pública de conformidad con el artículo 4 de la Ley Modelo sobre la Contratación Pública⁷ y el glosario de términos relacionados con la contratación pública utilizados en la Ley Modelo sobre la Contratación Pública⁷, así como por haber actualizado la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial⁸;

3. *Reconoce* la opinión expresada por la Comisión de que su secretaría debería desempeñar la función de archivo de la información publicada conforme al Reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado (“archivo de la transparencia”)⁹, invita al Secretario General a que considere la posibilidad de desempeñar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre la Transparencia, la función de archivo de la transparencia por medio de la secretaría de la Comisión, y solicita al Secretario General que informe a la Asamblea General y a la Comisión al respecto;

4. *Toma nota con interés* de las decisiones de la Comisión sobre su labor futura y de sus progresos en las esferas del arbitraje y la conciliación, la solución de controversias en línea, el comercio electrónico, el régimen de la insolvencia, las garantías reales, el derecho mercantil internacional destinado a reducir los obstáculos jurídicos que afectan a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en todo su ciclo de vida, y la colaboración entre los sectores público y privado, y encomia en particular las medidas adoptadas por la Comisión para mejorar la gestión de sus recursos y mantener y aumentar, al mismo tiempo, sus niveles actuales de actividad, entre otras cosas utilizando métodos de trabajo oficiosos cuando procede, teniendo debidamente en cuenta el proceso de negociación oficial¹⁰;

5. *Observa con aprecio* los proyectos de la Comisión destinados a promover la aplicación uniforme y efectiva de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York), hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958¹¹, incluida la preparación, en estrecha cooperación con expertos internacionales, de una guía sobre la Convención que se presentará a la Comisión en un período de sesiones futuro para que la examine¹²;

6. *Hace suyas* las gestiones e iniciativas de la Comisión, en su calidad de órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho

³ *Ibid.*, cap. III y anexo II.

⁴ *Ibid.*, cap. IV.

⁵ *Ibid.*, cap. V, secc. A.

⁶ *Ibid.*, secc. B.

⁷ *Ibid.*, cap. VI.

⁸ *Ibid.*, cap. V, secc. C.

⁹ *Ibid.*, párr. 80.

¹⁰ *Ibid.*, caps. III a V, VII, VIII y XV.

¹¹ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 330, núm. 4739.

¹² Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17)*, cap. III, secc. E.

mercantil internacional, encaminadas a mejorar la coordinación y la cooperación respecto de las actividades jurídicas de las organizaciones internacionales y regionales que se ocupan del derecho mercantil internacional y a promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional en esa esfera y, a este respecto, hace un llamamiento a las organizaciones internacionales y regionales competentes para que coordinen sus actividades jurídicas con las de la Comisión a fin de evitar la duplicación del trabajo y fomentar la eficiencia, uniformidad y coherencia en la modernización y armonización del derecho mercantil internacional;

7. *Reafirma* la importancia que reviste, en particular para los países en desarrollo, la labor de la Comisión relativa a la cooperación y asistencia técnicas en materia de reforma y desarrollo del derecho mercantil internacional y, a este respecto:

a) Acoge con beneplácito las iniciativas tomadas por la Comisión para ampliar, por conducto de su secretaría, su programa de cooperación y asistencia técnicas y, a ese respecto, alienta al Secretario General a que establezca asociaciones de colaboración con entidades estatales y no estatales para dar a conocer mejor la labor de la Comisión y facilitar la aplicación efectiva de las normas jurídicas que resulten de dicha labor;

b) Expresa su aprecio a la Comisión por las actividades de cooperación y asistencia técnicas realizadas y por la asistencia prestada para redactar legislación en materia de derecho mercantil internacional, y señala a la atención del Secretario General lo limitado de los recursos disponibles en esta esfera;

c) Expresa su aprecio a los gobiernos cuyas contribuciones permitieron realizar las actividades de cooperación y asistencia técnicas y hace un llamamiento a los gobiernos, a los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones, instituciones y particulares para que hagan contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario para la organización de simposios de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y, cuando corresponda, financien proyectos especiales, y para que presten apoyo de cualquier otra manera a la secretaría de la Comisión para realizar actividades de cooperación y asistencia técnicas, en particular en países en desarrollo;

d) Reitera su llamamiento al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a otros órganos responsables de la asistencia para el desarrollo, como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, así como a los gobiernos en el marco de sus programas de asistencia bilateral, para que presten apoyo al programa de cooperación y asistencia técnicas de la Comisión y cooperen con la Comisión y coordinen sus actividades con las de esta, habida cuenta de la pertinencia e importancia que tienen la labor y los programas de la Comisión para la promoción del estado de derecho a nivel nacional e internacional y para la aplicación de la agenda internacional para el desarrollo, incluido el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

8. *Recuerda* la importancia de la adhesión al reglamento y los métodos de trabajo de la Comisión, incluidas las deliberaciones transparentes e incluyentes, teniendo en cuenta el resumen de las conclusiones que figura en el anexo III del informe sobre la labor realizada en su 43º período de sesiones¹³, solicita a la

¹³ *Ibid.*, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17).

Secretaría que, con anterioridad a las reuniones de la Comisión y sus grupos de trabajo, publique un recordatorio de ese reglamento y métodos de trabajo a fin de garantizar la elevada calidad de la labor de la Comisión y alentar la evaluación de sus instrumentos y, a este respecto, recuerda sus resoluciones anteriores sobre esta cuestión;

9. *Acoge con beneplácito* las actividades del Centro Regional para Asia y el Pacífico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en la República de Corea, para proporcionar información y asistencia técnica a los países en desarrollo de la región en lo relacionado con las reformas del derecho mercantil internacional, observa con satisfacción las manifestaciones de interés de otros Estados en acoger centros regionales de la Comisión y solicita al Secretario General que la mantenga informada de los avances en el establecimiento de los centros regionales, en particular en lo que respecta a su situación financiera y presupuestaria¹⁴;

10. *Hace un llamamiento* a los gobiernos, a los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones, instituciones y particulares para que hagan contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario establecido con objeto de conceder asistencia para gastos de viaje a los países en desarrollo que son miembros de la Comisión, previa solicitud de estos y en consulta con el Secretario General, a fin de que vuelva a prestarse dicha asistencia y haya más expertos en representación de países en desarrollo en los períodos de sesiones de la Comisión y sus grupos de trabajo, de suerte que se incrementen los conocimientos técnicos y la capacidad a nivel local en esos países para crear un entorno de reglamentación que propicie la actividad empresarial, el comercio y la inversión;

11. *Decide*, a fin de asegurar la plena participación de todos los Estados Miembros en los períodos de sesiones de la Comisión y sus grupos de trabajo, continuar, en la Comisión Principal competente durante el sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General, su examen de la concesión de asistencia para gastos de viaje a los países menos adelantados que son miembros de la Comisión, previa solicitud de estos y en consulta con el Secretario General;

12. *Hace suya* la convicción de la Comisión de que la puesta en práctica y el empleo efectivo de normas modernas de derecho privado relativas al comercio internacional son esenciales para el fomento de la buena gobernanza, el desarrollo económico sostenido y la erradicación de la pobreza y el hambre, y de que la promoción del principio de legalidad en las relaciones comerciales debe formar parte integrante de la agenda más amplia de las Naciones Unidas para fomentar el estado de derecho a nivel nacional e internacional, entre otras cosas a través del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, que recibe asistencia de la Dependencia del Estado de Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario General;

13. *Observa* la mesa redonda sobre el estado de derecho celebrada en el marco del 46º período de sesiones de la Comisión y hace notar las observaciones transmitidas por la Comisión, en las que resaltó su papel en la promoción del estado de derecho y del arreglo pacífico de las controversias internacionales mediante su labor en las esferas del arbitraje y la conciliación, la transparencia en la solución de

¹⁴ *Ibid.*, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17), cap. XIII.

controversias entre los inversionistas y los Estados y la solución de controversias en línea, y su labor para lograr la adhesión universal a la Convención de Nueva York, así como su aplicación eficaz y su interpretación y aplicación uniformes¹⁵;

14. *Observa con satisfacción* que, en el párrafo 8 de la declaración de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional, aprobada por consenso como resolución 67/1, de 24 de septiembre de 2012, los Estados Miembros reconocieron la importancia de los marcos jurídicos justos, estables y previsibles para crear desarrollo, crecimiento económico y empleo inclusivos, sostenibles y equitativos, generar inversiones y facilitar la actividad empresarial y, a ese respecto, encomiaron la labor que realizaba la Comisión con objeto de modernizar y armonizar el derecho mercantil internacional, y que, en el párrafo 7 de esa declaración, los Estados Miembros expresaron su convicción de que el estado de derecho y el desarrollo estaban estrechamente relacionados y se reforzaban mutuamente;

15. *Reitera su solicitud* al Secretario General para que, de conformidad con sus resoluciones sobre aspectos relativos a la documentación¹⁶, en las que se insiste en particular en que la invitación a reducir la extensión de los documentos, cuando proceda, no debe ir en detrimento de la calidad de su presentación ni de su contenido, tenga presente las características especiales del mandato y las funciones de la Comisión en el desarrollo progresivo y la codificación del derecho mercantil internacional al aplicar a sus documentos las normas sobre límite de páginas¹⁷;

16. *Solicita* al Secretario General que siga publicando las normas de la Comisión y redactando actas resumidas de las sesiones de esta dedicadas a la formulación de textos normativos, incluidas las de los comités plenarios establecidos por la Comisión durante su período de sesiones anual, y toma nota de la decisión de la Comisión de seguir utilizando a título experimental las grabaciones digitales, junto con las actas resumidas, cuando proceda, con miras a evaluar, en su 47º período de sesiones, en 2014, la experiencia adquirida con la utilización de grabaciones digitales y, sobre la base de esa evaluación, adoptar una decisión sobre la posible sustitución de las actas resumidas por esas grabaciones¹⁸;

17. *Recuerda* el párrafo 48 de su resolución 66/246, de 24 de diciembre de 2011, relativo al régimen de rotación de sesiones entre Viena y Nueva York;

18. *Observa con reconocimiento* la labor de la Secretaría en lo relacionado con el sistema de recopilación y difusión de jurisprudencia relativa a los textos de la Comisión en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (sistema CLOUT), observa la gran cantidad de recursos que requiere el sistema, reconoce que se necesitan más recursos para mantenerlo y ampliarlo y, a este respecto, acoge con beneplácito las iniciativas de la Secretaría dirigidas a concertar alianzas con las instituciones interesadas y hace un llamamiento a los Gobiernos, los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones, las instituciones

¹⁵ *Ibid.*, cap. XIV, secc. C.

¹⁶ Resoluciones 52/214, secc. B, 57/283 B, secc. III, y 58/250, secc. III.

¹⁷ Resoluciones 59/39, párr. 9, y 65/21, párr. 18; véase también *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/59/17)*, párrs. 124 a 128.

¹⁸ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17)*, párr. 341.

y los particulares para que presten asistencia a la secretaría de la Comisión en su labor para concienciar sobre la disponibilidad y utilidad del sistema CLOUT en los círculos profesionales, académicos y del poder judicial y obtener la financiación necesaria para coordinar y ampliar el sistema y establecer, en la secretaría de la Comisión, un pilar centrado en la promoción de mecanismos para la interpretación uniforme de sus textos;

19. *Destaca* la importancia de promover la utilización de los textos dimanantes de la labor de la Comisión para la unificación y armonización a nivel mundial del derecho mercantil internacional y, a tal fin, insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de firmar o ratificar los convenios y convenciones o adherirse a ellos, incorporar las leyes modelo al derecho interno y alentar la utilización de otros textos pertinentes;

20. *Acoge con beneplácito* la labor sostenida de la Secretaría en la preparación de compilaciones de jurisprudencia relativa a los textos de la Comisión, incluida su amplia difusión, así como el aumento constante del número de resúmenes disponibles en el sistema CLOUT, en vista de la función que desempeñan las compilaciones y el sistema CLOUT como instrumentos importantes para promover la interpretación uniforme del derecho mercantil internacional, en particular fomentando la capacidad local de los magistrados, árbitros y otros profesionales del derecho para interpretar esas normas a la luz de su carácter internacional y de la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y la observancia de la buena fe en el comercio internacional.

Proyecto de resolución II

Revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza y cuarta parte de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

A. Revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza

La Asamblea General,

Recordando su resolución 2205 (XXI), de 17 de diciembre de 1966, en la que estableció la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y le confirió el mandato de promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional y, a ese respecto, tener presentes los intereses de todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo, en la evolución general del comercio internacional,

Recordando también su resolución 52/158, de 15 de diciembre de 1997, en que recomendó la utilización de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la Insolvencia Transfronteriza, que figura en su anexo,

Observando que en alrededor de 20 Estados se ha promulgado legislación basada en la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza,

Observando también el aumento generalizado de los procedimientos de insolvencia transfronteriza y, por consiguiente, las ocasiones cada vez más numerosas de utilizar y aplicar la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza en ellos, así como el establecimiento de jurisprudencia internacional en que se interpretan sus disposiciones,

Observando además que con frecuencia los tribunales se remiten a la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza, a fin de hallar orientación sobre los antecedentes de la redacción y la interpretación de sus disposiciones,

Reconociendo que ha surgido cierta incertidumbre en la jurisprudencia resultante de la aplicación en la práctica de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza con respecto a la interpretación de algunas de sus disposiciones,

Convencida de que al interpretar esas disposiciones sería conveniente tener en cuenta el origen internacional de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación,

Convencida también de la conveniencia de impartir, mediante la revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza, nuevas orientaciones con respecto a la interpretación y aplicación de determinados aspectos de la Ley Modelo a fin de facilitar su interpretación uniforme,

1. *Expresa su reconocimiento* a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por haber revisado la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza;

2. *Solicita* al Secretario General que publique, incluso por medios electrónicos, el texto de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza, junto con el texto de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza¹, y que lo transmita a los gobiernos y los órganos interesados a fin de que sea de conocimiento y acceso generalizado;

3. *Recomienda* que los legisladores, los responsables de la formulación de políticas, los jueces, los profesionales de la insolvencia y demás interesados en los regímenes de la insolvencia transfronteriza y los procedimientos correspondientes tomen debidamente en consideración, cuando proceda, la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza;

4. *Recomienda también* que todos los Estados sigan considerando la posibilidad de aplicar la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza e invita a los Estados que hayan promulgado legislación basada en la Ley Modelo a que informen de ello a la Comisión.

B. Cuarta parte de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia

La Asamblea General,

Recordando su resolución 2205 (XXI), de 17 de diciembre de 1966, en la que estableció la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y le confirió el mandato de promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional y, a ese respecto, tener presentes los intereses de todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo, en la evolución general del comercio internacional,

Recordando también sus resoluciones 59/40, de 2 de diciembre de 2004, en que recomendó la utilización de la *Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia* de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional² y 65/24, de 6 de diciembre de 2010, en que recomendó la utilización de la tercera parte de la *Guía*, relativa al trato otorgable a los grupos de empresas en situaciones de insolvencia,

Considerando que los regímenes de la insolvencia eficaces, además de establecer un proceso jurídico previsible para hacer frente a las dificultades financieras de las empresas con problemas y el marco necesario para su reorganización eficiente o su liquidación ordenada, deberían permitir también que se examinaran las circunstancias que hubieran dado lugar a su insolvencia y, en particular, la conducta de sus directores en el período anterior al inicio del procedimiento de insolvencia,

¹ Resolución 52/158, anexo.

² Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.05.V.10.

Observando que la *Guía Legislativa*, aunque aborda las obligaciones de los directores de una empresa una vez iniciado el procedimiento de insolvencia, no se ocupa de la conducta de los directores en el período cercano a la insolvencia ni de las obligaciones que podrían corresponderles en ese período,

Considerando que crear incentivos para que los directores adopten medidas adecuadas para hacer frente a los efectos de los problemas financieros de una empresa podría resultar decisivo para su reorganización o liquidación satisfactorias, y que esos incentivos deberían formar parte de un régimen de la insolvencia eficaz,

1. *Expresa su reconocimiento* a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por haber elaborado y aprobado la cuarta parte de la *Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia*, relativa a las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia³;

2. *Solicita* al Secretario General que publique, incluso por medios electrónicos, el texto de la cuarta parte de la *Guía Legislativa* y lo transmita a los gobiernos y demás órganos interesados;

3. *Recomienda* que todos los Estados utilicen la *Guía Legislativa* para evaluar la eficiencia económica de sus regímenes de la insolvencia y presten la debida atención a la *Guía* cuando se dispongan a revisar o promulgar una ley relativa a la insolvencia, e invita a los Estados que hayan utilizado la *Guía* a que informen de ello a la Comisión.

³ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17), cap. V, secc. B.*

Proyecto de resolución III

Guía de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales

La Asamblea General,

Reconociendo la importancia que reviste para todos los Estados disponer de regímenes eficientes de operaciones garantizadas que promuevan el acceso al crédito garantizado asequible,

Reconociendo también que el acceso al crédito garantizado asequible puede ayudar a todos los países, en particular a los países en desarrollo y a los países con economías en transición, en sus esfuerzos por lograr el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, el estado de derecho y la inclusión financiera,

Recordando su resolución 63/121, de 11 de diciembre de 2008, en que recomendó que todos los Estados tomaran debidamente en consideración la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas* de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional¹ al revisar o aprobar legislación relativa a las operaciones garantizadas,

Reconociendo que es probable que un régimen eficiente de operaciones garantizadas con un registro de garantías reales de acceso público, como el que se recomienda en la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas* aumente el acceso a un crédito garantizado asequible,

Observando con satisfacción que la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional² es coherente con la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*, de la que constituye un complemento útil, y que, las dos Guías, juntas, ofrecerán una orientación completa a los Estados con respecto a las cuestiones jurídicas y prácticas que deben resolverse al establecer un régimen moderno de operaciones garantizadas,

Observando que la reforma del régimen de las operaciones garantizadas no podría llevarse a cabo eficazmente sin el establecimiento de un registro de garantías reales eficiente y de acceso público, en el que pueda consignarse información acerca de la posible existencia de garantías reales sobre los bienes muebles, y que los Estados necesitan con urgencia orientación respecto del establecimiento y funcionamiento de tales registros,

Teniendo en cuenta que la armonización de los registros nacionales de garantías reales sobre la base de la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales aumentará probablemente la disponibilidad de crédito transfronterizo y, de ese modo, facilitará el desarrollo del comercio internacional, lo cual, si se logra de manera igualitaria y en beneficio de todos los Estados, es un elemento importante para promover las relaciones de amistad entre los Estados,

¹ Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.09.V.12.

² Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17)*, cap. IV.

Expresando su reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales internacionales e intergubernamentales que trabajan en la reforma del régimen de las operaciones garantizadas por su participación en la elaboración de la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales y su apoyo a ese proceso,

1. *Expresa su reconocimiento* a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por la finalización y aprobación de la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales²;

2. *Solicita* al Secretario General que publique la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales, incluso por medios electrónicos, y que le dé amplia difusión entre los gobiernos y demás órganos interesados, como las instituciones financieras y las cámaras de comercio nacionales e internacionales;

3. *Recomienda* que todos los Estados tomen debidamente en consideración la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales cuando revisen la legislación, las disposiciones administrativas o las directrices pertinentes, y la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas* de la Comisión¹ cuando revisen o aprueben la legislación relativa a las operaciones garantizadas, e invita a los Estados que hayan utilizado las Guías a que informen al respecto a la Comisión;

4. *Recomienda también* que todos los Estados sigan considerando la posibilidad de hacerse partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de créditos en el comercio internacional³, cuyos principios se reflejan en la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas* y cuyo anexo facultativo se refiere a la inscripción registral de las cesiones.

³ Resolución 56/81, anexo.

Proyecto de resolución IV
Reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre
Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado y Reglamento de
Arbitraje (según el texto revisado de 2010, con el nuevo artículo 1,
párrafo 4, aprobado en 2013) de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional

La Asamblea General,

Recordando su resolución 2205 (XXI), de 17 diciembre de 1966, en la que estableció la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y le confirió el mandato de promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional y, a ese respecto, tener presentes los intereses de todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo, en la evolución general del comercio internacional,

Reconociendo el valor del arbitraje como método para resolver las controversias que puedan surgir en el contexto de las relaciones internacionales y la amplia utilización del arbitraje para la solución de controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado,

Recordando sus resoluciones 31/98, de 15 de diciembre de 1976, y 65/22, de 6 de diciembre de 2010, en las que recomendó la utilización del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional¹,

Teniendo presente que el Reglamento de Arbitraje se utiliza ampliamente en la solución de controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado,

Reconociendo la necesidad de que, en las disposiciones sobre la transparencia en la solución de tales controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado, se tenga en cuenta el interés público al que afectan arbitrajes de esa índole,

Creyendo que un reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado contribuiría considerablemente al establecimiento de un marco jurídico armonizado para resolver de forma equitativa y eficiente las controversias internacionales en materia de inversiones, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y promover la buena gobernanza,

Observando que la Comisión, en su 46º período de sesiones, aprobó el Reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado² y enmendó el Reglamento de Arbitraje según el texto revisado de 2010 a fin de incluir, en un nuevo artículo 1, párrafo 4, una referencia al Reglamento sobre la Transparencia³,

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/31/17), cap. V, secc. C; e ibid., sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), cap. III y anexo I.*

² *Ibid., sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17), cap. III y anexo I.*

³ *Ibid., cap. III y anexo II.*

Observando también que el Reglamento sobre la Transparencia puede utilizarse en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con otras disposiciones distintas del Reglamento de Arbitraje o en procedimientos especiales,

Observando además que la preparación del Reglamento sobre la Transparencia fue objeto de las debidas deliberaciones en la Comisión y de que en esas deliberaciones se efectuaron consultas con gobiernos y con organizaciones no gubernamentales internacionales e intergubernamentales interesadas,

1. *Expresa su reconocimiento* a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por haber preparado y aprobado el Reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado² y el Reglamento de Arbitraje (según el texto revisado de 2010, con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013)³, que figuran en el anexo del informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 46º período de sesiones⁴;

2. *Solicita* al Secretario General que publique, incluso por medios electrónicos, y divulgue ampliamente el texto del Reglamento sobre la Transparencia, junto con el Reglamento de Arbitraje (según el texto revisado de 2010, con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013) y como texto independiente, y que los transmita a los gobiernos y a las organizaciones interesadas en la esfera de la solución de controversias;

3. *Recomienda* la utilización del Reglamento sobre la Transparencia en la solución de controversias en materia de inversiones dentro del ámbito de su aplicación, definido en el artículo 1 del Reglamento, e invita a los Estados Miembros que han elegido incluir el Reglamento en sus tratados a que informen de ello a la Comisión;

4. *Recomienda también* que, a reserva de toda disposición del tratado pertinente que pueda requerir un grado de transparencia mayor que el previsto en el Reglamento sobre la Transparencia, este último se aplique mediante mecanismos apropiados a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con un tratado que prevea la protección de los inversores o las inversiones celebrado antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento, en la medida en que dicha aplicación sea compatible con esos tratados.

⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17).*

D. Resoluciones 68/106, 68/107, 68/108, 68/109, y 68/116 de la Asamblea General

68/106. Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 46º período de sesiones

La Asamblea General,

Recordando su resolución 2205 (XXI), de 17 de diciembre de 1966, en la que estableció la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y le confirió el mandato de promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional y, a ese respecto, tener presentes los intereses de todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo, en la evolución general del comercio internacional,

Reafirmando su convencimiento de que la modernización y armonización progresivas del derecho mercantil internacional, al reducir o eliminar los obstáculos jurídicos que se oponen al flujo del comercio internacional, especialmente los que afectan a los países en desarrollo, contribuirían de modo significativo a la cooperación económica universal entre todos los Estados sobre una base de igualdad, equidad, interés común y respeto del estado de derecho, así como a la eliminación de la discriminación en el comercio internacional y, por consiguiente, a la paz, la estabilidad y el bienestar de todos los pueblos,

Habiendo examinado el informe de la Comisión¹,

Reiterando su preocupación por el hecho de que las actividades realizadas por otros órganos en el ámbito del derecho mercantil internacional sin coordinación suficiente con la Comisión puedan dar lugar a una duplicación no deseable del trabajo y no se ajusten al objetivo de fomentar la eficiencia, uniformidad y coherencia en la unificación y armonización del derecho mercantil internacional,

Reafirmando el mandato conferido a la Comisión para que, en su calidad de órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional, coordine las actividades jurídicas en la materia, en particular con el fin de evitar la duplicación del trabajo, especialmente entre las organizaciones que elaboran normas de comercio internacional, y fomentar la eficiencia, uniformidad y coherencia en la modernización y armonización del derecho mercantil internacional y, por conducto de su secretaría, continúe manteniendo una estrecha cooperación con otros órganos y organizaciones internacionales que se ocupan del derecho mercantil internacional, incluidas las organizaciones regionales,

1. *Toma nota con aprecio* del informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional¹;

2. *Encomia* a la Comisión por haber finalizado y aprobado el Reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado², el Reglamento de Arbitraje (según el texto revisado de 2010, con el

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17).*

² *Ibid.*, cap. III y anexo I.

nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013)³, la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales⁴, la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza⁵, la cuarta parte de la *Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia*, relativa a las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia⁶, las directrices para la promulgación de un reglamento de la contratación pública de conformidad con el artículo 4 de la Ley Modelo sobre la Contratación Pública⁷ y el glosario de términos relacionados con la contratación pública utilizados en la Ley Modelo sobre la Contratación Pública⁷, así como por haber actualizado la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial⁸;

3. *Reconoce* la opinión expresada por la Comisión de que su secretaría debería desempeñar la función de archivo de la información publicada conforme al Reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado (“archivo de la transparencia”)⁹, invita al Secretario General a que considere la posibilidad de desempeñar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre la Transparencia, la función de archivo de la transparencia por medio de la secretaría de la Comisión, y solicita al Secretario General que informe a la Asamblea General y a la Comisión al respecto;

4. *Toma nota con interés* de las decisiones de la Comisión sobre su labor futura y de sus progresos en las esferas del arbitraje y la conciliación, la solución de controversias en línea, el comercio electrónico, el régimen de la insolvencia, las garantías reales, el derecho mercantil internacional destinado a reducir los obstáculos jurídicos que afectan a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en todo su ciclo de vida, y la colaboración entre los sectores público y privado, y encomia en particular las medidas adoptadas por la Comisión para mejorar la gestión de sus recursos y mantener y aumentar, al mismo tiempo, sus niveles actuales de actividad, entre otras cosas utilizando métodos de trabajo oficiosos cuando procede, teniendo debidamente en cuenta el proceso de negociación oficial¹⁰;

5. *Observa con aprecio* los proyectos de la Comisión destinados a promover la aplicación uniforme y efectiva de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York), hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958¹¹, incluida la preparación, en estrecha cooperación con expertos internacionales, de una guía sobre la Convención que se presentará a la Comisión en un período de sesiones futuro para que la examine¹²;

6. *Hace suyas* las gestiones e iniciativas de la Comisión, en su calidad de órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho

³ *Ibid.*, cap. III y anexo II.

⁴ *Ibid.*, cap. IV.

⁵ *Ibid.*, cap. V, secc. A.

⁶ *Ibid.*, secc. B.

⁷ *Ibid.*, cap. VI.

⁸ *Ibid.*, cap. V, secc. C.

⁹ *Ibid.*, párr. 80.

¹⁰ *Ibid.*, caps. III a V, VII, VIII y XV.

¹¹ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 330, núm. 4739.

¹² Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17)*, cap. III, secc. E.

mercantil internacional, encaminadas a mejorar la coordinación y la cooperación respecto de las actividades jurídicas de las organizaciones internacionales y regionales que se ocupan del derecho mercantil internacional y a promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional en esa esfera y, a este respecto, hace un llamamiento a las organizaciones internacionales y regionales competentes para que coordinen sus actividades jurídicas con las de la Comisión a fin de evitar la duplicación del trabajo y fomentar la eficiencia, uniformidad y coherencia en la modernización y armonización del derecho mercantil internacional;

7. *Reafirma* la importancia que reviste, en particular para los países en desarrollo, la labor de la Comisión relativa a la cooperación y asistencia técnicas en materia de reforma y desarrollo del derecho mercantil internacional y, a este respecto:

a) Acoge con beneplácito las iniciativas tomadas por la Comisión para ampliar, por conducto de su secretaría, su programa de cooperación y asistencia técnicas y, a ese respecto, alienta al Secretario General a que establezca asociaciones de colaboración con entidades estatales y no estatales para dar a conocer mejor la labor de la Comisión y facilitar la aplicación efectiva de las normas jurídicas que resulten de dicha labor;

b) Expresa su aprecio a la Comisión por las actividades de cooperación y asistencia técnicas realizadas y por la asistencia prestada para redactar legislación en materia de derecho mercantil internacional, y señala a la atención del Secretario General lo limitado de los recursos disponibles en esta esfera;

c) Expresa su aprecio a los gobiernos cuyas contribuciones permitieron realizar las actividades de cooperación y asistencia técnicas y hace un llamamiento a los gobiernos, a los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones, instituciones y particulares para que hagan contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario para la organización de simposios de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y, cuando corresponda, financien proyectos especiales, y para que presten apoyo de cualquier otra manera a la secretaría de la Comisión para realizar actividades de cooperación y asistencia técnicas, en particular en países en desarrollo;

d) Reitera su llamamiento al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a otros órganos responsables de la asistencia para el desarrollo, como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, así como a los gobiernos en el marco de sus programas de asistencia bilateral, para que presten apoyo al programa de cooperación y asistencia técnicas de la Comisión y cooperen con la Comisión y coordinen sus actividades con las de esta, habida cuenta de la pertinencia e importancia que tienen la labor y los programas de la Comisión para la promoción del estado de derecho a nivel nacional e internacional y para la aplicación de la agenda internacional para el desarrollo, incluido el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

8. *Recuerda* la importancia de la adhesión al reglamento y los métodos de trabajo de la Comisión, incluidas las deliberaciones transparentes e incluyentes, teniendo en cuenta el resumen de las conclusiones que figura en el anexo III del informe sobre la labor realizada en su 43º período de sesiones¹³, solicita a la

¹³ *Ibid.*, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17).

Secretaría que, con anterioridad a las reuniones de la Comisión y sus grupos de trabajo, publique un recordatorio de ese reglamento y métodos de trabajo a fin de garantizar la elevada calidad de la labor de la Comisión y alentar la evaluación de sus instrumentos y, a este respecto, recuerda sus resoluciones anteriores sobre esta cuestión;

9. *Acoge con beneplácito* las actividades del Centro Regional para Asia y el Pacífico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en la República de Corea, para proporcionar información y asistencia técnica a los países en desarrollo de la región en lo relacionado con las reformas del derecho mercantil internacional, observa con satisfacción las manifestaciones de interés de otros Estados en acoger centros regionales de la Comisión y solicita al Secretario General que la mantenga informada de los avances en el establecimiento de los centros regionales, en particular en lo que respecta a su situación financiera y presupuestaria¹⁴;

10. *Hace un llamamiento* a los gobiernos, a los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones, instituciones y particulares para que hagan contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario establecido con objeto de conceder asistencia para gastos de viaje a los países en desarrollo que son miembros de la Comisión, previa solicitud de estos y en consulta con el Secretario General, a fin de que vuelva a prestarse dicha asistencia y haya más expertos en representación de países en desarrollo en los períodos de sesiones de la Comisión y sus grupos de trabajo, de suerte que se incrementen los conocimientos técnicos y la capacidad a nivel local en esos países para crear un entorno de reglamentación que propicie la actividad empresarial, el comercio y la inversión;

11. *Decide*, a fin de asegurar la plena participación de todos los Estados Miembros en los períodos de sesiones de la Comisión y sus grupos de trabajo, continuar, en la Comisión Principal competente durante el sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General, su examen de la concesión de asistencia para gastos de viaje a los países menos adelantados que son miembros de la Comisión, previa solicitud de estos y en consulta con el Secretario General;

12. *Hace suya* la convicción de la Comisión de que la puesta en práctica y el empleo efectivo de normas modernas de derecho privado relativas al comercio internacional son esenciales para el fomento de la buena gobernanza, el desarrollo económico sostenido y la erradicación de la pobreza y el hambre, y de que la promoción del principio de legalidad en las relaciones comerciales debe formar parte integrante de la agenda más amplia de las Naciones Unidas para fomentar el estado de derecho a nivel nacional e internacional, entre otras cosas a través del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, que recibe asistencia de la Dependencia del Estado de Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario General;

13. *Observa* la mesa redonda sobre el estado de derecho celebrada en el marco del 46º período de sesiones de la Comisión y hace notar las observaciones transmitidas por la Comisión, en las que resaltó su papel en la promoción del estado de derecho y del arreglo pacífico de las controversias internacionales mediante su labor en las esferas del arbitraje y la conciliación, la transparencia en la solución de

¹⁴ *Ibid.*, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17), cap. XIII.

controversias entre los inversionistas y los Estados y la solución de controversias en línea, y su labor para lograr la adhesión universal a la Convención de Nueva York, así como su aplicación eficaz y su interpretación y aplicación uniformes¹⁵;

14. *Observa con satisfacción* que, en el párrafo 8 de la declaración de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional, aprobada por consenso como resolución 67/1, de 24 de septiembre de 2012, los Estados Miembros reconocieron la importancia de los marcos jurídicos justos, estables y previsibles para crear desarrollo, crecimiento económico y empleo inclusivos, sostenibles y equitativos, generar inversiones y facilitar la actividad empresarial y, a ese respecto, encomiaron la labor que realizaba la Comisión con objeto de modernizar y armonizar el derecho mercantil internacional, y que, en el párrafo 7 de esa declaración, los Estados Miembros expresaron su convicción de que el estado de derecho y el desarrollo estaban estrechamente relacionados y se reforzaban mutuamente;

15. *Reitera su solicitud* al Secretario General para que, de conformidad con sus resoluciones sobre aspectos relativos a la documentación¹⁶, en las que se insiste en particular en que la invitación a reducir la extensión de los documentos, cuando proceda, no debe ir en detrimento de la calidad de su presentación ni de su contenido, tenga presente las características especiales del mandato y las funciones de la Comisión en el desarrollo progresivo y la codificación del derecho mercantil internacional al aplicar a sus documentos las normas sobre límite de páginas¹⁷;

16. *Solicita* al Secretario General que siga publicando las normas de la Comisión y redactando actas resumidas de las sesiones de esta dedicadas a la formulación de textos normativos, incluidas las de los comités plenarios establecidos por la Comisión durante su período de sesiones anual, y toma nota de la decisión de la Comisión de seguir utilizando a título experimental las grabaciones digitales, junto con las actas resumidas, cuando proceda, con miras a evaluar, en su 47º período de sesiones, en 2014, la experiencia adquirida con la utilización de grabaciones digitales y, sobre la base de esa evaluación, adoptar una decisión sobre la posible sustitución de las actas resumidas por esas grabaciones¹⁸;

17. *Recuerda* el párrafo 48 de su resolución 66/246, de 24 de diciembre de 2011, relativo al régimen de rotación de sesiones entre Viena y Nueva York;

18. *Observa con reconocimiento* la labor de la Secretaría en lo relacionado con el sistema de recopilación y difusión de jurisprudencia relativa a los textos de la Comisión en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (sistema CLOUT), observa la gran cantidad de recursos que requiere el sistema, reconoce que se necesitan más recursos para mantenerlo y ampliarlo y, a este respecto, acoge con beneplácito las iniciativas de la Secretaría dirigidas a concertar alianzas con las instituciones interesadas y hace un llamamiento a los Gobiernos, los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones, las instituciones

¹⁵ *Ibid.*, cap. XIV, secc. C.

¹⁶ Resoluciones 52/214, secc. B, 57/283 B, secc. III, y 58/250, secc. III.

¹⁷ Resoluciones 59/39, párr. 9, y 65/21, párr. 18; véase también *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/59/17)*, párrs. 124 a 128.

¹⁸ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17)*, párr. 341.

y los particulares para que presten asistencia a la secretaría de la Comisión en su labor para concienciar sobre la disponibilidad y utilidad del sistema CLOUT en los círculos profesionales, académicos y del poder judicial y obtener la financiación necesaria para coordinar y ampliar el sistema y establecer, en la secretaría de la Comisión, un pilar centrado en la promoción de mecanismos para la interpretación uniforme de sus textos;

19. *Destaca* la importancia de promover la utilización de los textos dimanantes de la labor de la Comisión para la unificación y armonización a nivel mundial del derecho mercantil internacional y, a tal fin, insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de firmar o ratificar los convenios y convenciones o adherirse a ellos, incorporar las leyes modelo al derecho interno y alentar la utilización de otros textos pertinentes;

20. *Acoge con beneplácito* la labor sostenida de la Secretaría en la preparación de compilaciones de jurisprudencia relativa a los textos de la Comisión, incluida su amplia difusión, así como el aumento constante del número de resúmenes disponibles en el sistema CLOUT, en vista de la función que desempeñan las compilaciones y el sistema CLOUT como instrumentos importantes para promover la interpretación uniforme del derecho mercantil internacional, en particular fomentando la capacidad local de los magistrados, árbitros y otros profesionales del derecho para interpretar esas normas a la luz de su carácter internacional y de la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y la observancia de la buena fe en el comercio internacional.

*68ª sesión plenaria
16 de diciembre de 2013*

68/107. Revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de a Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza y cuarta parte de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

A

REVISIÓN DE LA GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNO DE LA LEY
MODELO SOBRE LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA

La Asamblea General,

Recordando su resolución 2205 (XXI), de 17 de diciembre de 1966, en la que estableció la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y le confirió el mandato de promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional y, a ese respecto, tener presentes los intereses de todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo, en la evolución general del comercio internacional,

Recordando también su resolución 52/158, de 15 de diciembre de 1997, en que recomendó la utilización de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la Insolvencia Transfronteriza, que figura en su anexo,

Observando que en alrededor de 20 Estados se ha promulgado legislación basada en la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza,

Observando también el aumento generalizado de los procedimientos de insolvencia transfronteriza y, por consiguiente, las ocasiones cada vez más numerosas de utilizar y aplicar la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza en ellos, así como el establecimiento de jurisprudencia internacional en que se interpretan sus disposiciones,

Observando además que con frecuencia los tribunales se remiten a la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza¹, a fin de hallar orientación sobre los antecedentes de la redacción y la interpretación de sus disposiciones,

Reconociendo que ha surgido cierta incertidumbre en la jurisprudencia resultante de la aplicación en la práctica de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza con respecto a la interpretación de algunas de sus disposiciones,

Convencida de que al interpretar esas disposiciones sería conveniente tener en cuenta el origen internacional de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación,

Convencida también de la conveniencia de impartir, mediante la revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza, nuevas orientaciones con respecto a la interpretación y aplicación de determinados aspectos de la Ley Modelo a fin de facilitar su interpretación uniforme,

¹ A/CN.9/442, anexo.

1. *Expresa su reconocimiento* a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por haber revisado la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza¹;
2. *Solicita* al Secretario General que publique, incluso por medios electrónicos, el texto de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza, junto con el texto de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza², y que lo transmita a los gobiernos y los órganos interesados a fin de que sea de conocimiento y acceso generalizado;
3. *Recomienda* que los legisladores, los responsables de la formulación de políticas, los jueces, los profesionales de la insolvencia y demás interesados en los regímenes de la insolvencia transfronteriza y los procedimientos correspondientes tomen debidamente en consideración, cuando proceda, la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza;
4. *Recomienda también* que todos los Estados sigan considerando la posibilidad de aplicar la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza e invita a los Estados que hayan promulgado legislación basada en la Ley Modelo a que informen de ello a la Comisión.

*68ª sesión plenaria
16 de diciembre de 2013*

B

CUARTA PARTE DE LA GUÍA LEGISLATIVA SOBRE EL RÉGIMEN DE LA INSOLVENCIA

La Asamblea General,

Recordando su resolución 2205 (XXI), de 17 de diciembre de 1966, en la que estableció la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y le confirió el mandato de promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional y, a ese respecto, tener presentes los intereses de todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo, en la evolución general del comercio internacional,

Recordando también sus resoluciones 59/40, de 2 de diciembre de 2004, en que recomendó la utilización de la *Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia* de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional³, y 65/24, de 6 de diciembre de 2010, en que recomendó la utilización de la tercera parte de la *Guía*, relativa al trato otorgable a los grupos de empresas en situaciones de insolvencia,

Considerando que los regímenes de la insolvencia eficaces, además de establecer un proceso jurídico previsible para hacer frente a las dificultades financieras de las empresas con problemas y el marco necesario para su reorganización eficiente o su liquidación ordenada, deberían permitir también que se

² Resolución 52/158, anexo.

³ Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.05.V.10.

examinaran las circunstancias que hubieran dado lugar a su insolvencia y, en particular, la conducta de sus directores en el período anterior al inicio del procedimiento de insolvencia,

Observando que la *Guía Legislativa*, aunque aborda las obligaciones de los directores de una empresa una vez iniciado el procedimiento de insolvencia, no se ocupa de la conducta de los directores en el período cercano a la insolvencia ni de las obligaciones que podrían corresponderles en ese período,

Considerando que crear incentivos para que los directores adopten medidas adecuadas para hacer frente a los efectos de los problemas financieros de una empresa podría resultar decisivo para su reorganización o liquidación satisfactorias, y que esos incentivos deberían formar parte de un régimen de la insolvencia eficaz,

1. *Expresa su reconocimiento* a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por haber elaborado y aprobado la cuarta parte de la *Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia*, relativa a las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia⁴;

2. *Solicita* al Secretario General que publique, *incluso* por medios electrónicos, el texto de la cuarta parte de la *Guía Legislativa* y lo transmita a los gobiernos y demás órganos interesados;

3. *Recomienda* que todos los Estados utilicen la *Guía Legislativa* para evaluar la eficiencia económica de sus regímenes de la insolvencia y presten la debida atención a la *Guía* cuando se dispongan a revisar o promulgar una ley relativa a la insolvencia, e invita a los Estados que hayan utilizado la *Guía* a que informen de ello a la Comisión.

68ª sesión plenaria
16 de diciembre de 2013

⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17), cap. V, secc. B.*

68/108. Guía de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales

La Asamblea General,

Reconociendo la importancia que reviste para todos los Estados disponer de regímenes eficientes de operaciones garantizadas que promuevan el acceso al crédito garantizado asequible,

Reconociendo también que el acceso al crédito garantizado asequible puede ayudar a todos los países, en particular a los países en desarrollo y a los países con economías en transición, en sus esfuerzos por lograr el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, el estado de derecho y la inclusión financiera,

Recordando su resolución 63/121, de 11 de diciembre de 2008, en que recomendó que todos los Estados tomaran debidamente en consideración la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas* de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional¹ al revisar o aprobar legislación relativa a las operaciones garantizadas,

Reconociendo que es probable que un régimen eficiente de operaciones garantizadas con un registro de garantías reales de acceso público, como el que se recomienda en la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas* aumente el acceso a un crédito garantizado asequible,

Observando con satisfacción que la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional² es coherente con la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*, de la que constituye un complemento útil, y que, las dos Guías, juntas, ofrecerán una orientación completa a los Estados con respecto a las cuestiones jurídicas y prácticas que deben resolverse al establecer un régimen moderno de operaciones garantizadas,

Observando que la reforma del régimen de las operaciones garantizadas no podría llevarse a cabo eficazmente sin el establecimiento de un registro de garantías reales eficiente y de acceso público, en el que pueda consignarse información acerca de la posible existencia de garantías reales sobre los bienes muebles, y que los Estados necesitan con urgencia orientación respecto del establecimiento y funcionamiento de tales registros,

Teniendo en cuenta que la armonización de los registros nacionales de garantías reales sobre la base de la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales aumentará probablemente la disponibilidad de crédito transfronterizo y, de ese modo, facilitará el desarrollo del comercio internacional, lo cual, si se logra de manera igualitaria y en beneficio de todos los Estados, es un elemento importante para promover las relaciones de amistad entre los Estados,

Expresando su reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales internacionales e intergubernamentales que trabajan en la reforma del régimen de

¹ Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.09.V.12.

² Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17)*, cap. IV.

las operaciones garantizadas por su participación en la elaboración de la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales y su apoyo a ese proceso,

1. *Expresa su reconocimiento* a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por la finalización y aprobación de la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales²;

2. *Solicita* al Secretario General que publique la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales, incluso por medios electrónicos, y que le dé amplia difusión entre los gobiernos y demás órganos interesados, como las instituciones financieras y las cámaras de comercio nacionales e internacionales;

3. *Recomienda* que todos los Estados tomen debidamente en consideración la Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales cuando revisen la legislación, las disposiciones administrativas o las directrices pertinentes, y la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas* de la Comisión¹ cuando revisen o aprueben la legislación relativa a las operaciones garantizadas, e invita a los Estados que hayan utilizado las Guías a que informen al respecto a la Comisión;

4. *Recomienda también* que todos los Estados sigan considerando la posibilidad de hacerse partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de créditos en el comercio internacional³, cuyos principios se reflejan en la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas* y cuyo anexo facultativo se refiere a la inscripción registral de las cesiones.

68ª sesión plenaria
16 de diciembre de 2013

³ Resolución 56/81, anexo.

68/109. Reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado y Reglamento de Arbitraje (según el texto revisado de 2010, con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013) de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

La Asamblea General,

Recordando su resolución 2205 (XXI), de 17 diciembre de 1966, en la que estableció la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y le confirió el mandato de promover la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional y, a ese respecto, tener presentes los intereses de todos los pueblos, en particular los de los países en desarrollo, en la evolución general del comercio internacional,

Reconociendo el valor del arbitraje como método para resolver las controversias que puedan surgir en el contexto de las relaciones internacionales y la amplia utilización del arbitraje para la solución de controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado,

Recordando sus resoluciones 31/98, de 15 de diciembre de 1976, y 65/22, de 6 de diciembre de 2010, en las que recomendó la utilización del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional¹,

Teniendo presente que el Reglamento de Arbitraje se utiliza ampliamente en la solución de controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado,

Reconociendo la necesidad de que, en las disposiciones sobre la transparencia en la solución de tales controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado, se tenga en cuenta el interés público al que afectan arbitrajes de esa índole,

Creyendo que un reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado contribuiría considerablemente al establecimiento de un marco jurídico armonizado para resolver de forma equitativa y eficiente las controversias internacionales en materia de inversiones, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y promover la buena gobernanza,

Observando que la Comisión, en su 46º período de sesiones, aprobó el Reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado² y enmendó el Reglamento de Arbitraje según el texto revisado de 2010 a fin de incluir, en un nuevo artículo 1, párrafo 4, una referencia al Reglamento sobre la Transparencia³,

Observando también que el Reglamento sobre la Transparencia puede utilizarse en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con otras disposiciones distintas del Reglamento de Arbitraje o en procedimientos especiales,

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/31/17), cap. V, secc. C; e ibid., sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), cap. III y anexo I.*

² *Ibid., sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17), cap. III y anexo I.*

³ *Ibid., cap. III y anexo II.*

Observando además que la preparación del Reglamento sobre la Transparencia fue objeto de las debidas deliberaciones en la Comisión y de que en esas deliberaciones se efectuaron consultas con gobiernos y con organizaciones no gubernamentales internacionales e intergubernamentales interesadas,

1. *Expresa su reconocimiento* a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por haber preparado y aprobado el Reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado² y el Reglamento de Arbitraje (según el texto revisado de 2010, con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013)³, que figuran en el anexo del informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 46º período de sesiones⁴;

2. *Solicita* al Secretario General que publique, incluso por medios electrónicos, y divulgue ampliamente el texto del Reglamento sobre la Transparencia, junto con el Reglamento de Arbitraje (según el texto revisado de 2010, con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013) y como texto independiente, y que los transmita a los gobiernos y a las organizaciones interesadas en la esfera de la solución de controversias;

3. *Recomienda* la utilización del Reglamento sobre la Transparencia en la solución de controversias en materia de inversiones dentro del ámbito de su aplicación, definido en el artículo 1 del Reglamento, e invita a los Estados Miembros que han elegido incluir el Reglamento en sus tratados a que informen de ello a la Comisión;

4. *Recomienda también* que, a reserva de toda disposición del tratado pertinente que pueda requerir un grado de transparencia mayor que el previsto en el Reglamento sobre la Transparencia, este último se aplique mediante mecanismos apropiados a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con un tratado que prevea la protección de los inversores o las inversiones celebrado antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento, en la medida en que dicha aplicación sea compatible con esos tratados.

68ª sesión plenaria
16 de diciembre de 2013

⁴ Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/68/17).

68/116. El estado de derecho en los planos nacional e internacional

La Asamblea General,

Recordando su resolución 67/97, de 14 de diciembre de 2012,

Reafirmando su compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, que son el fundamento indispensable de un mundo más pacífico, próspero y justo, y reiterando su determinación de promover su estricto respeto y de establecer una paz justa y duradera en todo el mundo,

Reafirmando que los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia están vinculados entre sí, se refuerzan mutuamente y forman parte de los valores y principios fundamentales, universales e indivisibles de las Naciones Unidas,

Reafirmando también la necesidad del respeto y la aplicación universales del estado de derecho en los planos nacional e internacional y su compromiso solemne con un orden internacional basado en el estado de derecho y el derecho internacional, que, junto con los principios de la justicia, es esencial para la coexistencia pacífica y la cooperación entre los Estados,

Convencida de que el progreso del estado de derecho en los planos nacional e internacional es esencial para el crecimiento económico sostenido, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre y la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y reconociendo que la seguridad colectiva depende de que exista una cooperación eficaz, de conformidad con la Carta y el derecho internacional, contra las amenazas transnacionales,

Reafirmando el deber de todos los Estados de abstenerse en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas y de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia, de conformidad con el Capítulo VI de la Carta, y exhortando a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia según lo dispuesto en su Estatuto,

Convencida de que la promoción y el respeto del estado de derecho en los planos nacional e internacional, así como la justicia y la buena gobernanza, deben guiar las actividades de las Naciones Unidas y sus Estados Miembros,

Recordando el párrafo 134 e) del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005¹,

1. *Recuerda* la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional, celebrada durante la serie de sesiones de alto nivel de su sexagésimo séptimo período de sesiones, y la declaración aprobada en dicha reunión²;

¹ Resolución 60/1.

² Resolución 67/1.

2. *Toma nota* del informe anual del Secretario General sobre el fortalecimiento y la coordinación de las actividades de las Naciones Unidas orientadas a la promoción del estado de derecho³;

3. *Reafirma* el papel de la Asamblea General en lo que respecta al fomento del desarrollo progresivo del derecho internacional y de su codificación, y reafirma además que los Estados deben cumplir todas las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho internacional;

4. *Reafirma también* que es imprescindible respetar y promover el estado de derecho en el plano internacional de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas;

5. *Acoge con beneplácito* el diálogo iniciado por el Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho y la Dependencia sobre el Estado de Derecho de la Oficina Ejecutiva del Secretario General con los Estados Miembros sobre el tema “Promoción del estado de derecho en el plano internacional”, y pide que este diálogo continúe con miras a fomentar el estado de derecho en el plano internacional;

6. *Destaca* la importancia de que el estado de derecho se respete en el plano nacional y la necesidad de que los Estados Miembros que lo soliciten reciban más apoyo para dar cumplimiento en el ámbito nacional a sus respectivas obligaciones internacionales mediante el aumento de la asistencia técnica y la creación de capacidad;

7. *Reitera su solicitud* al Secretario General de que asegure una mayor coordinación y coherencia entre las entidades de las Naciones Unidas y con los donantes y beneficiarios, y reitera su petición de que se evalúen más detenidamente la eficacia de dichas actividades y, en particular, las posibles medidas para mejorar la eficacia de las actividades de creación de capacidad;

8. *Pide*, en este contexto, que se fomente el diálogo entre todas las partes interesadas con miras a situar las perspectivas nacionales en el centro de la asistencia en el ámbito del estado de derecho, con el fin de fortalecer la implicación nacional;

9. *Exhorta* al Secretario General y al sistema de las Naciones Unidas a que, según proceda, aborden sistemáticamente los aspectos relacionados con el estado de derecho en las actividades pertinentes, incluida la participación de la mujer en actividades relacionadas con el estado de derecho, reconociendo la importancia que este reviste en prácticamente todos los ámbitos de la labor de las Naciones Unidas;

10. *Expresa pleno apoyo* a la función general de coordinación y armonización que, dentro del sistema de las Naciones Unidas y conforme a los mandatos vigentes, desempeña el Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, asistido por la Dependencia sobre el Estado de Derecho, bajo la dirección del Vicesecretario General;

11. *Solicita* al Secretario General que presente puntualmente su próximo informe anual sobre las actividades de las Naciones Unidas orientadas a la

³ A/68/213.

promoción del estado de derecho, de conformidad con el párrafo 5 de su resolución 63/128, de 11 de diciembre de 2008;

12. *Reconoce* la importancia de que se restablezca la confianza en el estado de derecho como elemento fundamental de la justicia de transición;

13. *Alienta* al Secretario General y al sistema de las Naciones Unidas a que otorguen alta prioridad a las actividades orientadas a la promoción del estado de derecho;

14. *Invita* a la Corte Internacional de Justicia, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Comisión de Derecho Internacional a que sigan formulando observaciones, en sus respectivos informes a la Asamblea General, sobre sus funciones actuales en la promoción del estado de derecho;

15. *Invita* al Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho y a la Dependencia sobre el Estado de Derecho a que continúen manteniendo contactos periódicos con los Estados Miembros, en particular en reuniones informativas oficiosas;

16. *Destaca* la necesidad de dotar a la Dependencia sobre el Estado de Derecho de los fondos y el personal necesarios para que pueda llevar a cabo su labor de manera sostenible y eficaz, e insta al Secretario General y a los Estados Miembros a que sigan apoyando el funcionamiento de la Dependencia;

17. *Decide* incluir en el programa provisional de su sexagésimo noveno período de sesiones el tema titulado “El estado de derecho en los planos nacional e internacional”, e invita a los Estados Miembros a que centren sus observaciones durante el próximo debate de la Sexta Comisión en el subtema “Puesta en común de las prácticas nacionales de los Estados para el fortalecimiento del estado de derecho mediante el acceso a la justicia”.

*68ª sesión plenaria
16 de diciembre de 2013*

Segunda parte

ESTUDIOS E INFORMES SOBRE
CUESTIONES CONCRETAS

I. ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

A. Informe del Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación sobre la labor realizada en su 57º período de sesiones (Viena, 1 a 5 de octubre de 2012)

(A/CN.9/760)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-4
II. Organización del período de sesiones	5-11
III. Deliberaciones y decisiones	12
IV. Preparación de una norma jurídica acerca de la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	13-141
A. Norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	13-141
1. Artículo 3 - Publicación de [documentos] [información]	13-35
2. Artículo 4 - Publicación de laudos arbitrales	36-38
3. Artículo 5 - Presentaciones a cargo de terceros	39-57
4. Artículo 6 - Presentaciones de una parte en el tratado que no sea litigante	58-75
5. Artículo 7 - Audiencias	76-88
6. Artículo 8 - Excepciones a la norma de la transparencia	89-119
7. Artículo 9 - Archivo de la información puesta a disposición del público	120-122
8. Observaciones generales sobre la segunda lectura del proyecto de reglamento sobre la transparencia	123-130
9. Artículo 1 - Ámbito de aplicación	131-141

I. Introducción

1. En su 43° período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010) la Comisión, con respecto a la labor futura en materia de solución de controversias comerciales, recordó la decisión adoptada en su 41° período de sesiones (Nueva York, 16 de junio a 3 de julio de 2008)¹ de que el tema de la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado se abordara, con carácter prioritario, inmediatamente después de que hubiera finalizado la revisión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. La Comisión encomendó a su Grupo de Trabajo II la tarea de preparar una norma jurídica sobre dicho tema².
2. En su 44° período de sesiones (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011), la Comisión reiteró la opinión que había expresado en su 41° período de sesiones acerca de la importancia de que se garantizara la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado. La Comisión confirmó que la cuestión de la aplicabilidad de la norma jurídica sobre la transparencia a los tratados de inversiones existentes formaba parte del mandato del Grupo de Trabajo y era una cuestión que revestía un gran interés práctico, habida cuenta del gran número de tratados ya concertados³. Asimismo, la Comisión convino en considerar que la cuestión de una posible intervención en el arbitraje de un Estado no litigante que fuera parte en el tratado de inversiones formaba parte del mandato del Grupo de Trabajo. Se planteaba la cuestión de si en la norma jurídica sobre la transparencia debía o no abordarse ese derecho de intervención y, en caso afirmativo, si la determinación del alcance y de las modalidades de tal intervención deberían ser objeto de un examen más profundo por parte del Grupo de Trabajo⁴.
3. En su 45° período de sesiones (Nueva York, 25 de junio a 6 de julio de 2012) la Comisión reafirmó la importancia de garantizar la transparencia de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, reconocida en sus períodos de sesiones 41° y 44°, celebrados respectivamente en 2008 y 2011⁵, e instó al Grupo de Trabajo a que prosiguiera y concluyera su labor relativa a la norma sobre la transparencia, para someterla a su examen de preferencia en su período de sesiones siguiente⁶.
4. La recopilación más reciente de referencias relativas a la evolución del examen de la labor del Grupo de Trabajo por la Comisión se encuentra en los párrafos 5 a 14 del documento A/CN.9/WG.II/WP.171.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1)*, párr. 314.

² *Ibid.*, sexagésimo quinto período de sesiones, *Suplemento núm. 17 y corrección (A/65/17)*, párr. 190.

³ *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, *Suplemento núm. 17 (A/66/17)*, párr. 200.

⁴ *Ibid.*, párr. 202.

⁵ *Ibid.*, sexagésimo tercer período de sesiones, *Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1)*, párr. 314; *ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, *Suplemento núm. 17 (A/66/17)*, párr. 200.

⁶ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, *Suplemento núm. 17 (A/67/17)*, párr. 69.

II. Organización del período de sesiones

5. El Grupo de Trabajo, formado por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 57º período de sesiones en Viena del 1 al 5 de octubre de 2012. Asistieron al período de sesiones los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Croacia, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Malasia, Mauricio, México, Noruega, Pakistán, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Ucrania y Venezuela (República Bolivariana de).

6. Asistieron al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Belarús, Bélgica, Chipre, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, Finlandia, Guatemala, Indonesia, Liberia, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, República Dominicana, Rumania, Suecia y Suiza.

7. También asistieron al período de sesiones observadores de la Unión Europea.

8. Asimismo asistieron al período de sesiones observadores de las siguientes organizaciones internacionales:

a) *Sistema de las Naciones Unidas*: Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD);

b) *Organizaciones intergubernamentales*: Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), Corte Permanente de Arbitraje, Liga de los Estados Árabes y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE);

c) *Organizaciones no gubernamentales invitadas*: *American Bar Association (ABA)*, Asociación de Alumnos del Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Asociación de Arbitraje de los Estados Unidos (AAA), Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York (ABCNY), Asociación Internacional de Abogados, Asociación para la Promoción del Arbitraje en África (APAA), Asociación Suiza de Arbitraje, *Barreau de Paris*, *Center for International Environmental Law (CIEL)*, Centro Belga de Arbitraje y Mediación (CEPANI), Centro Internacional de Arbitraje de Viena, Comisión Internacional de Arbitraje Económico y Comercial de China (CIETAC), *Comité Français de l'Arbitrage (CFA)*, Consejo de Comercio del Pakistán, Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial, *Construction Industry Arbitration Council (CIAC)*, Corte Internacional de Arbitraje, Facultad de Arbitraje Internacional de la Universidad Queen Mary de Londres, Foro de Conciliación y Arbitraje Internacionales, Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, Instituto Europeo de Derecho, *International Insolvency Institute (III)*, Junta de Arbitraje Comercial de Corea, *Miami International Arbitration Society (MIAS)*, Tribunal de Arbitraje de Madrid y *Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCCI)*.

9. El Grupo de Trabajo eligió la siguiente Mesa:

Presidente: Sr. Salim Moollan (Mauricio)

Relator: Sr. Muhammad Mustaqeem De Gama (Sudáfrica)

10. Obraron en poder del Grupo de Trabajo los siguientes documentos: a) programa provisional (A/CN.9/WG.II/WP.171); b) notas de la Secretaría relativas a la preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (A/CN.9/WG.II/WP.172 y su adición y A/CN.9/WG.II/WP.169 y su adición; c) una nota de la Secretaría en la que se reproducen las observaciones presentadas por instituciones arbitrales acerca de las relaciones entre el proyecto de reglamento sobre la transparencia y sus respectivas reglas institucionales (A/CN.9/WG.II/WP.173), y d) una nota de la Secretaría que contenía una propuesta presentada por los Gobiernos de la Argentina, Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, México, Noruega y Sudáfrica con respecto a la determinación del ámbito de aplicación del proyecto de reglamento sobre la transparencia (A/CN.9/WG.II/WP.174).

11. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:

1. Apertura del período de sesiones.
2. Elección de la Mesa.
3. Aprobación del programa.
4. Preparación de una norma jurídica acerca de la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado.
5. Organización de la labor futura.
6. Otros asuntos.
7. Aprobación del informe.

III. Deliberaciones y decisiones

12. El Grupo de Trabajo reanudó su labor sobre el tema 4 del programa tomando como base las notas preparadas por la Secretaría (A/CN.9/WG.II/WP.169 y su adición; A/CN.9/WG.II/WP.172 y su adición, A/CN.9/WG.II/WP.173 y A/CN.9/WG.II/WP.174). Las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo respecto de este tema se recogen en el capítulo IV. Se solicitó a la Secretaría que preparara i) un proyecto revisado de la norma sobre la transparencia sobre la base de las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo, y ii) el texto de un convenio sobre la transparencia aplicable en los arbitrajes, entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, y el texto de una declaración unilateral (véase el párr. 141).

IV. Preparación de una norma jurídica acerca de la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado

A. Norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado

1. Artículo 3 - Publicación de [documentos] [información]

13. El Grupo de Trabajo examinó el artículo 3, enunciado en el párrafo 29 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169, en el que se recogía una propuesta formulada en su 55º período de sesiones de que en la disposición sobre la publicación de documentos o información se previera: i) una lista de los documentos que debían ponerse a disposición del público; ii) la facultad discrecional del tribunal arbitral de ordenar la publicación de documentos o información adicionales; iii) el derecho de terceros de solicitar acceso a los documentos o información adicionales, y iv) la publicación de documentos o información (véanse A/CN.9/736, párrs. 54 a 66; A/CN.9/741, párr. 111).

Párrafo 1

Lista de pruebas y pruebas

14. Se observó que en el párrafo 1 figuraban entre corchetes, en la lista de la información que habría de darse a conocer “automáticamente” (es decir, a reserva de las excepciones enunciadas en el artículo 8 únicamente), dos categorías de documentos: i) una lista de todas las pruebas correspondientes a los documentos que habrían de darse a conocer de conformidad con el párrafo 1, y ii) las pruebas mismas.

15. Algunas delegaciones expresaron la preocupación de que sería demasiado engorroso presentar “automáticamente” las pruebas mismas con arreglo al artículo 3, párrafo 1, debido a que el material probatorio podría ser voluminoso y además podría ser necesario proceder a expurgarlo. Se convino en que las pruebas se eliminarían del artículo 3, párrafo 1, pero quedarían sujetas a divulgación con carácter discrecional en virtud de otras disposiciones del artículo 3. Se opinó que la publicación de un cuadro en que se enumeraran las pruebas sería menos onerosa y, por otra parte, que dar a conocer los escritos pertinentes en virtud del artículo 3, párrafo 1, bastaría para asegurarse de que el público estuviera informado de la existencia de pruebas y podía, por consiguiente, solicitarse conforme a lo dispuesto en el artículo 3. También se opinó que crear y dar a conocer una lista de pruebas sería una tarea engorrosa, en particular para las partes de países en desarrollo o de países de escasos recursos.

16. Se sugirió que, si en el curso del procedimiento ya se hubiese preparado una lista de las pruebas, no sería muy difícil para las partes dar a conocer ese documento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 1. Tras un debate, el Grupo de Trabajo convino en que, en los casos en que ya existiera una lista de pruebas, habría la obligación de darla a conocer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 1, pero que si no se hubiese presentado una lista de pruebas en el curso del procedimiento, no se exigiría crearla a efectos de darla a conocer de

conformidad con el artículo 3. Se solicitó a la secretaría que formulara un texto en que se reflejara ese acuerdo.

Dictámenes periciales y declaraciones de testigos

17. El Grupo de Trabajo consideró la posibilidad de que en la lista de documentos previstos en el artículo 3, párrafo 1, se incluyeran los dictámenes periciales y las declaraciones de los testigos. Se opinó que esos documentos eran parte esencial de la información sobre los hechos en una causa y que deberían ponerse a disposición del público a fin de promover plenamente el objetivo de fortalecer la transparencia en las controversias entre inversionistas y el Estado.

18. Algunas delegaciones observaron que el hecho de no incluir los dictámenes periciales ni las declaraciones de los testigos en el párrafo 1 no socavaría el objetivo de transparencia, ya que tanto las partes litigantes como cualquier otra persona podían solicitar su publicación en virtud de otras disposiciones del artículo 3. Se dijo también que podía ofrecerse al público información suficientemente detallada en relación con el tema de la controversia, pero no ponerlo en pie de igualdad con las partes.

19. Otra opinión fue que en las demás disposiciones del artículo 3 conforme a las cuales se solicitarían esos documentos (párrafos 2 y 3) no se preveía la presentación “automática” a solicitud de los interesados, sino que, por el contrario, se necesitaban facultades discrecionales y consultas adicionales en relación con su publicación. Se observó también que añadir un elemento discrecional para determinar si se deberían divulgar o no las declaraciones de los testigos o los dictámenes periciales impondría una carga considerable al tribunal arbitral y, en consecuencia, debido a la consiguiente demora del procedimiento y a la necesidad de que las partes presentaran los escritos pertinentes, también a las partes.

20. Se propuso que los dictámenes periciales y las declaraciones de los testigos se excluyeran del ámbito del artículo 3, párrafo 1, y que se creara una categoría separada en la disposición relativa a la publicación. Concretamente, se propuso que esos documentos no se dieran a conocer “automáticamente” con arreglo al párrafo 1, ni estuvieran sujetos a una decisión del tribunal arbitral con arreglo a los párrafos 2 o 3. Se propuso, en cambio, que se diesen a conocer “automáticamente” a solicitud de cualquier persona, es decir, sin estar supeditados a las facultades discrecionales ni a las decisiones del tribunal arbitral, a reserva de las excepciones enunciadas en el artículo 8. Al formular esa propuesta se aclaró que, al igual que en el consenso del Grupo de Trabajo recogido en los párrafos 15 y 16 en relación con las pruebas de los escritos de demanda y contestación o las presentaciones, los dictámenes periciales y las declaraciones de los testigos se darían a conocer sin el material probatorio, que debería solicitarse por separado.

21. Tras un debate, se llegó a un consenso en relación con la propuesta enunciada en el párrafo 20. Las delegaciones que no eran partidarias de esa solución pidieron que se hiciera constar que se oponían a la publicación “automática” de las declaraciones de los testigos y los dictámenes periciales en respuesta a solicitudes concretas y, en particular, que dudaban de que así se redujera la carga para el tribunal arbitral.

22. Se encomendó a la secretaría que redactara un nuevo artículo 3, párrafo 2, que reflejara el acuerdo expuesto en el párrafo 20 para examinarlo durante la tercera lectura del proyecto de reglamento.

Transcripciones

23. El Grupo de Trabajo consideró también la posibilidad de incluir las transcripciones en la lista de documentos del artículo 3, párrafo 1. Recordó sus deliberaciones anteriores y el acuerdo al que había llegado, recogido en los párrafos 107 a 109 del documento A/CN.9/736, de incluir las transcripciones en el artículo 3, párrafo 1, en la inteligencia de que la información confidencial que allí constase podría expurgarse, y, por consiguiente, que las transcripciones deberían tratarse de la misma manera que los demás documentos enumerados en el párrafo 1.

24. El Grupo de Trabajo reafirmó esa conclusión y convino en que se incluyeran las transcripciones en la lista de documentos del artículo 3, párrafo 1. Se encomendó a la secretaría que introdujera ligeras modificaciones de redacción, cuando procediera, para aclarar que en el artículo no se imponía la obligación de presentar transcripciones cuando no se hubieran hecho en el curso de las actuaciones.

Párrafos 2 y 3

25. Se observó que en los párrafos 2 y 3 (según figuran en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169) se establecía una distinción en relación con la persona que formulaba la solicitud (partes litigantes y otras personas) y no en relación con la clase de documento de que se tratara. Se sugirió que los dictámenes periciales y las declaraciones de los testigos únicamente deberían ponerse a disposición de la persona que formulara la solicitud, entre otras cosas, a fin de proteger el derecho de propiedad intelectual de los peritos y de dar protección a los testigos. Se discrepó con esa sugerencia debido a que i) no existía ningún mecanismo práctico para evitar la publicación más amplia de un documento o de información una vez que se hubiese dado a conocer a un tercero, y ii) toda disposición que limitara el acceso del público sería incompatible con el concepto de transparencia y, en cualquier caso, podría ser discriminatoria.

26. Se indicó que, cuando una persona hubiese solicitado un documento o información en virtud del artículo 3, y el tribunal, en ejercicio de sus facultades discrecionales, le hubiese dado acceso a ellos, era difícil prever qué razones podría dar posteriormente el tribunal para rechazar la solicitud de otra persona que necesitara el mismo material. Se dijo que, a fin de lograr una norma coherente sobre la transparencia, ni la divulgación de documentos o información ni el acceso a ellos deberían estar limitados a determinados grupos de personas. Se recordó que el artículo 8 limitaría el suministro de información por motivos de confidencialidad.

27. Se hizo una distinción entre publicación y acceso. Se dijo que la razón original para dividir el texto en dos párrafos (2 y 3) no fue que el Grupo de Trabajo considerara que el acceso debería limitarse a un grupo de personas en especial, sino que consideró que había categorías de documentos o información que no se prestaban para ser publicados, y que sería más apropiado referirse al derecho de acceso a los documentos y no a su publicación.

28. Se propuso fusionar los párrafos 2 y 3 en un solo párrafo con objeto de establecer una disposición uniforme para presentar solicitudes al tribunal con

respecto a “otros documentos” que no estuvieran previstos en el párrafo 1 ni en el recién propuesto párrafo 2 (relativo a los dictámenes periciales y las declaraciones de testigos, enunciado arriba en el párrafo 21). Esa propuesta funcionaría siempre y cuando: i) quedara sujeta a lo dispuesto en el artículo 8; y ii) el tribunal arbitral, por iniciativa propia o a solicitud de una parte litigante o de una persona que no fuera parte litigante, tuviera la facultad discrecional para decidir si y cómo se daría a conocer al público todo otro documento que no estuviera comprendido en el ámbito de los párrafos 1 o 2.

29. Se opinó que, en interés del fácil manejo de las actuaciones, ni el tribunal debería estar facultado para tomar la iniciativa de publicar documentos ni terceros deberían tener el derecho de solicitarlo. También se sugirió que en el reglamento sobre la transparencia se incluyeran además disposiciones sobre las solicitudes presentadas después de que se dictara el laudo definitivo.

30. El Grupo de Trabajo llegó a un consenso sobre la propuesta enunciada anteriormente en el párrafo 28 y encomendó a la secretaría que formulara un texto en el que se reflejara ese acuerdo y se tuvieran en cuenta las consideraciones expresadas en dicho párrafo.

Párrafo 4

31. En relación con el párrafo 4, se señaló que, tras la fusión de los párrafos 2 y 3, se requería introducir las modificaciones consiguientes. Se planteó la cuestión de la manera en que los “otros documentos”, en el sentido en que se utilizaban esos términos en el párrafo 28, se darían a conocer al público. Por lo demás, el Grupo de Trabajo expresó su acuerdo con el contenido del párrafo 4.

Párrafos 1 a 4: relación con el artículo 8

32. Se expresó la preocupación de que los párrafos 1 a 4 del artículo 3 (que figuran en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169, e incluidas las enmiendas introducidas en los párrafos 14 a 31 del presente documento) se referían únicamente a las excepciones previstas en el artículo 8, y no al artículo 8 en su conjunto, lo que planteaba dudas acerca de la manera en que funcionaría en la práctica el vínculo entre el artículo 3 y el artículo 8. En respuesta a esa preocupación, el Grupo de Trabajo convino en que se modificaran los párrafos 1 a 4 del artículo 3 y el párrafo 3 del artículo 8.

33. Concretamente, en relación con los párrafos 1 a 3 del artículo 3 (según figuran en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169, e incluidas las modificaciones indicadas en los párrafos 14 al 31 del presente documento), se convino en suprimir la expresión “A reserva de las excepciones enunciadas en” en las respectivas primeras líneas, de modo que esos párrafos comenzaran de la siguiente manera: “A reserva de lo dispuesto en el artículo 8 (...)”.

34. Habida cuenta de la preocupación expresada arriba en el párrafo 32, el Grupo de Trabajo examinó un proyecto revisado de párrafo 4 del artículo 3 (correspondiente al párrafo 4 del artículo 3 enunciado en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169), cuyo texto era el siguiente: “4. Los documentos puestos a disposición del público con arreglo a lo establecido en los párrafos 1 y 2 serán comunicados por el tribunal arbitral al archivo mencionado en el artículo 9 lo antes posible, de conformidad con las disposiciones a que se hace referencia en el artículo 8, párrafo 3. Los documentos

puestos a disposición [del público] [de la persona que solicite acceso a ellos] con arreglo a lo establecido en el párrafo 3 pueden ser comunicados por el tribunal arbitral al archivo mencionado en el artículo 9 a medida que se disponga de ellos, y cuando proceda, en su forma expurgada de conformidad con el artículo 8. El archivo hará públicos oportunamente los documentos en la forma y el idioma en que los reciba”.

35. El Grupo de Trabajo consideró aceptable el proyecto de texto y convino en que debería conservarse.

2. Artículo 4 - Publicación de los laudos arbitrales

36. El Grupo de Trabajo examinó el artículo 4, enunciado en el párrafo 33 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169, relativo a la publicación de los laudos arbitrales. Recordó que en su 55º período de sesiones se había expresado amplio apoyo a ese artículo (A/CN.9/736, párr. 67).

37. Se sugirió que los laudos arbitrales, cuya divulgación automática estaba prevista actualmente en el artículo 4, se incluyeran en la lista de documentos del artículo 3, párrafo 1, habida cuenta de que se aplicaba el mismo procedimiento “automático” de divulgación a los documentos de ese artículo, incluidas las providencias y decisiones del tribunal arbitral. En respuesta a esa sugerencia, se sugirió que se otorgara al tribunal arbitral la facultad discrecional, a solicitud de una parte, para ordenar el aplazamiento de la publicación de un laudo arbitral cuando hubiese otros procedimientos pendientes que afectaran a esa parte y que abordaran cuestiones de hecho o de derecho análogas, a fin de no prejuzgar el resultado de esos otros procedimientos. Esa sugerencia no fue apoyada por considerarse que entrañaba un posible conflicto con un importante objetivo de la labor del Grupo de Trabajo, y se indicó que una disposición de esa índole retrasaría indebidamente la publicación de numerosos laudos arbitrales, habida cuenta de la similitud de las cuestiones de hecho y de derecho planteadas en las diversas actuaciones.

38. Tras un debate, se convino en que se enmendara la última línea del artículo 3, párrafo 1, sustituyendo las palabras “y las providencias y decisiones del tribunal arbitral” por las palabras “y las providencias, decisiones y laudos del tribunal arbitral”. Se aclaró que el párrafo 4 del artículo 3 sería suficiente para satisfacer el requisito relativo a la comunicación enunciado actualmente en el párrafo 2 del artículo 4. En consecuencia, se convino en que el artículo 4 ya no era necesario y que debería suprimirse.

3. Artículo 5 - Presentaciones a cargo de terceros

39. El Grupo de Trabajo examinó el artículo 5, enunciado en el párrafo 35 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169, relativo a la presentación de escritos por un tercero.

Párrafo 1

40. Se preguntó si en el párrafo 1 la palabra “podrá” tenía por objeto hacer referencia al procedimiento de compaginación previsto en el párrafo 5 del artículo 1. Si ese era el propósito, se sugirió que se dejara en claro agregando la expresión “,

en ejercicio de sus facultades discrecionales,” en la primera línea del párrafo 1 entre las palabras “tribunal arbitral” y “podrá”. Se dijo que esa expresión se empleaba en otras partes del reglamento cuando se quería dejar en claro que el tribunal debía tener presente el criterio de compaginación mencionado en el párrafo 5 del artículo 1 del reglamento. En respuesta, se dijo que el artículo 5 era algo diferente porque en él los proyectos de párrafos 3 y 5 contenían orientaciones concretas sobre la forma en que el tribunal debía abordar el ejercicio de sus facultades discrecionales con arreglo a lo dispuesto en dicho artículo. El Grupo de Trabajo compartió esa interpretación.

41. Se formuló la propuesta de que los escritos presentados por terceros quedasen sujetos al requisito obligatorio de consulta previa con las partes litigantes. La propuesta no recibió apoyo.

42. Tras un debate, el Grupo de Trabajo decidió que se conservara el contenido del párrafo 1 del artículo 5, enunciado en el párrafo 35 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169.

Párrafo 2

43. Habida cuenta de las preocupaciones expresadas en relación, entre otras cosas, con el significado y el alcance de la expresión “ayuda financiera o de otra índole” y con el hecho de que la revelación estaba limitada a la ayuda en la preparación de la presentación y no de forma más general, el Grupo de Trabajo convino en examinar una propuesta de modificación del párrafo 2 del artículo 5. El texto de la propuesta, que fue presentada conjuntamente por varias delegaciones (el “proyecto de propuesta”) era el siguiente: “2. El tercero que desee hacer una presentación lo solicitará al tribunal arbitral y presentará por escrito la información siguiente en uno de los idiomas del arbitraje, de manera concisa y respetando el límite de páginas que determine el tribunal: a) descripción del tercero, indicando, si procede, la organización de que sea miembro y su condición jurídica (por ejemplo, asociación profesional u otra entidad no gubernamental), sus objetivos generales, la índole de sus actividades y toda entidad matriz (incluida toda entidad que controle directa o indirectamente al tercero); b) revelación de si el tercero tiene o no algún tipo de afiliación, directa o indirecta, con algunas de las partes litigantes; c) información sobre todo gobierno, persona u organización que haya prestado ayuda financiera o de otra índole para la preparación de la presentación, o que haya aportado más del 25% de los ingresos del tercero en los dos años anteriores a la solicitud; d) descripción de la índole del interés del tercero en el arbitraje; y e) indicación de las cuestiones concretas de hecho o de derecho suscitadas en el arbitraje que el tercero desee abordar en su presentación.”

Apartados a), d) y e) del proyecto de propuesta

44. Se aprobó el contenido de los apartados a), d) y e) enunciados en el párrafo 35 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169, sin que se formularan objeciones a los ligeros cambios consiguientes introducidos en el proyecto de propuesta.

Apartado b) del proyecto de propuesta

45. El Grupo de Trabajo examinó el apartado b) del proyecto de propuesta. Algunas delegaciones opinaban que, además de determinar si existía una relación

entre el tercero y una parte litigante, también se debería exigir que se precisara la índole de esa relación.

46. Esa sugerencia recibió amplio apoyo y, en consecuencia, se decidió modificar el texto del apartado b) del proyecto de propuesta de la siguiente manera: “b) revelación de toda vinculación, directa o indirecta, que tenga el tercero con alguna de las partes litigantes;”

Apartado c) del proyecto de propuesta

47. En relación con el apartado c), el Grupo de Trabajo examinó la cuestión de si un umbral porcentual sería suficiente para dar a entender el tipo y grado de asistencia que se proponía abordar el reglamento.

48. Se dijo que, en particular en el caso de una entidad receptora de gran envergadura, en que una elevada cifra absoluta de asistencia financiera no representaría una proporción importante de sus ingresos totales, ese porcentaje no indicaría si la asistencia había sido realmente considerable. Se dijo también que expresar el volumen de asistencia como porcentaje de los ingresos daría lugar a que no se presentara información si la asistencia, aun cuando fuese considerable, hubiese sido “en especie”, o hubiese estado apenas por debajo del umbral. Por otra parte, se opinó que el porcentaje determinado en función del volumen global de negocios indicaría claramente si la influencia había sido considerable, y que los terceros se podrían beneficiar de la orientación impartida a fin de comprender mejor los requisitos de una norma que preveía una obligación amplia de revelar información sobre sus propias actividades.

49. A raíz de esas deliberaciones, se propuso una solución de avenencia que tenía por objeto promover más efectivamente el objetivo de la disposición, caracterizado por algunos como exigencia de que los terceros revelaran toda ayuda financiera considerable que hubieran recibido de cualquier gobierno, persona u organización. Según esa propuesta, se sustituiría la frase “aportado más del 25% de los ingresos del tercero en los dos años anteriores” por la frase “prestado ayuda considerable en los dos años anteriores”. Además, se propuso que se aclarara a los terceros lo que podía constituir ayuda considerable añadiendo, inmediatamente después, la frase “como por ejemplo, financiando el 20% de las operaciones globales del tercero anualmente”. Se indicó que se utilizaban las palabras “operaciones globales” en lugar de “ingresos” para abarcar circunstancias en que la ayuda prestada al tercero fuese mayor que los propios ingresos. No se formularon objeciones a la propuesta de utilizar la cifra del 20%, en lugar de la del 25% propuesta originalmente.

50. Algunas delegaciones reiteraron su preocupación de que se utilizara un porcentaje, aun cuando sirviese únicamente de orientación, ya que podía considerarse un umbral por debajo del cual no era necesario revelar esa información. Se respondió que la cifra del 20% se mencionaba a manera de ejemplo ilustrativo y el hecho de que la ayuda fuese considerable dependería siempre de las circunstancias del caso; se sugirió, en consecuencia, que se modificara la propuesta enunciada anteriormente en el párrafo 43 remplazando, antes de la cifra del 20%, las palabras “más del”, por “aproximadamente”, o “alrededor del”, con objeto de indicar que no se trataba de un umbral definitivo. Tras deliberar al respecto, se aprobó esa propuesta y se encomendó a la secretaría que utilizara una formulación adecuada en

relación con esa cuestión. También se le encomendó que considerara la posibilidad de cambiar de lugar la palabra “anualmente”, si eso servía para aclarar el texto, y puntualizando que la cifra del 20% se refería a las operaciones de un año y no de dos.

51. Por consiguiente, el texto aprobado del apartado c), a reserva de las ligeras modificaciones de redacción que habría de introducir la secretaría, sería el siguiente: “c) información sobre todo gobierno, persona u organización que haya prestado al tercero i) ayuda financiera o de otra índole para la preparación de la presentación, o ii) ayuda considerable en cualquiera de los dos años anteriores a la solicitud, como, por ejemplo, la financiación de [aproximadamente el] [alrededor del] 20% de sus operaciones globales anualmente.”

Párrafo 3

52. Se sugirió que en la parte b) del párrafo 3 se suprimieran las palabras “de hecho o” por entenderse que la presentación de escritos por parte de terceros debería relacionarse únicamente con la determinación de cuestiones de derecho en el procedimiento, y no de cuestiones de hecho. Se respondió que los terceros solían proporcionar información importante sobre los hechos que vendría a satisfacer el requisito expresado en el párrafo 3 en el sentido de aportar “perspectivas, conocimientos particulares o puntos de vista distintos a los de las partes litigantes”, y que excluir esa función haría un flaco servicio al tribunal, el cual, en virtud del artículo 5, puede determinar lo que le sirve de ayuda.

53. Tras un debate, el Grupo de Trabajo decidió que se conservara el contenido del párrafo 3 del artículo 5, según figura en el párrafo 35 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169.

Párrafo 4

54. El Grupo de Trabajo examinó el párrafo 4 del artículo 5. Se propuso que se añadiera un apartado con una disposición global a efectos de que los escritos presentados por los terceros cumplieran, además de los criterios enunciados en los apartados a) a d) del párrafo 4, toda otra condición establecida por el tribunal arbitral.

55. Se opinó que esa autoridad discrecional era inherente al tribunal arbitral y que mencionar el derecho de este a imponer condiciones acerca de la presentación de escritos podría crear, sin necesidad, la obligación de abordar expresamente esa autoridad en otras partes del reglamento, para evitar dudas. Tras un debate, se convino en que el párrafo 4 del artículo 5 se conservara en la forma enunciada en el párrafo 35 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169.

Párrafo 5

56. Tras examinar ese párrafo, el Grupo de Trabajo decidió conservar el contenido del párrafo 5 del artículo 5, enunciado en el párrafo 35 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169.

Párrafo 6

57. Se aceptó la propuesta de modificar ligeramente el párrafo 6 suprimiendo la palabra “también” del proyecto de texto. El Grupo de Trabajo encomendó además a la secretaría que introdujera los cambios consiguientes a fin de armonizar el texto con otros párrafos pertinentes del reglamento, entre ellos el párrafo 5 del artículo 6.

4. Artículo 6 - Presentaciones de una parte en el tratado que no sea litigante

58. El Grupo de Trabajo examinó el artículo 6, enunciado en el párrafo 37 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169.

Párrafo 1

59. Las opiniones estaban divididas con respecto a exigir que el tribunal aceptara (“aceptará”) o tuviera la facultad discrecional para aceptar (“podrá aceptar”) de partes en el tratado que no fueran litigantes presentaciones sobre cuestiones relacionadas con la interpretación del tratado.

60. Se formularon opiniones en apoyo de la primera opción (“aceptará”), a saber, que como la parte no litigante había concluido el tratado, la interpretación de este podría afectar a sus derecho de allí en adelante en procedimientos futuros; que las intervenciones de la parte podrían ser útiles al tribunal para comprender el tratado, y que la experiencia arbitral demostraba que una parte no litigante que fuera parte en el tratado casi nunca intervenía simplemente para proteger los intereses de su inversionista. Se declaró que algunos tratados estipulaban que una parte no litigante tenía derecho a presentar al tribunal su opinión sobre la interpretación del tratado.

61. En apoyo de la otra opción (“podrá aceptar”) se dijo que lo dispuesto en el artículo 6 no parecía guardar relación con la transparencia y tendría el efecto de facilitar la protección diplomática de un inversionista por un Estado; que debía otorgarse la facultad discrecional al tribunal a fin de ser coherente con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 6; y que exigir la aceptación de esa clase de presentaciones en todos los casos podría dar lugar a la politización del procedimiento.

62. Las opiniones también estuvieron divididas respecto de la cuestión de si el tribunal podía invitar, por iniciativa propia, a una parte en el tratado que no fuera litigante a hacer presentaciones sobre cuestiones relacionadas con la interpretación del tratado.

63. El artículo 6, párrafo 1, quedó abierto a deliberaciones posteriores. El Grupo de Trabajo invitó a los Estados a que examinaran sus tratados para determinar si contenían disposiciones que otorgaran a la parte no litigante el derecho a presentar al tribunal su opinión sobre la interpretación del tratado.

*Párrafo 2**Cuestiones de derecho, cuestiones de hecho o cuestiones que sean objeto del litigio*

64. Se examinaron las expresiones que figuraban entre corchetes en el párrafo 2 del artículo 6, con objeto concretamente de determinar si en el párrafo se debía hacer referencia a las presentaciones de partes en el tratado que no fueran litigantes en relación con “cuestiones de derecho”, “cuestiones de derecho o de hecho”,

o “cuestiones que sean objeto del litigio”. Se aclaró que en la medida en que el párrafo 2 del artículo 6 tuviera por objeto abordar cuestiones de derecho, estas no serían las mismas a las que se hacía referencia en relación con la interpretación del tratado en el párrafo 1.

65. Algunas delegaciones expresaron la opinión de que esa disposición debería limitarse a las cuestiones de derecho, a lo que se respondió señalando que en la práctica era difícil diferenciar entre las cuestiones de derecho y de hecho. Se indicó que la expresión “cuestiones que sean objeto del litigio” comprendía tanto cuestiones de derecho como de hecho y que la facultad discrecional del tribunal arbitral serviría de filtro para determinar qué presentaciones le serían útiles.

66. Según algunas opiniones, se debería suprimir el párrafo 2 del artículo 6, en vista de la incertidumbre que había respecto del significado de la expresiones “cuestiones de derecho o de hecho” y “cuestiones que sean objeto de litigio”, e igualmente del peligro de abrir la puerta a la protección diplomática.

67. Después de deliberar sobre esa cuestión, el Grupo de Trabajo convino en que se sustituyeran las expresiones que figuraban entre corchetes por la expresión “cuestiones que sean objeto del litigio”, que era compatible con la formulación utilizada en el párrafo 1 del artículo 5, y se añadiera la palabra “otras” (es decir, “otras cuestiones que sean objeto del litigio”), lo que se consideró conveniente para establecer una diferencia entre el alcance del párrafo 2 y el del párrafo 1 precedente en relación con las cuestiones relativas a la interpretación del tratado.

Invitación a partes en el tratado que no sean litigantes

68. Se planteó otra duda en relación con la posibilidad de permitir al tribunal que, por iniciativa propia, invitara a partes en el tratado que no fueran litigantes a hacer otras presentaciones sobre cuestiones que fueran objeto del litigio, invitación esta que estaba prevista en el proyecto de párrafo 2, enunciado en el párrafo 37 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169.

69. Se sugirió que en el párrafo 2 del artículo 6, no se facultara al tribunal a invitar a hacer presentaciones, por dos razones principales: que i) una invitación de esa índole podía dar lugar a la politización de las controversias y podría introducir aspectos relacionados con la protección diplomática, y ii) que una invitación de esa índole pondría a la parte en el tratado que no fuera litigante en una posición más privilegiada que la de cualquier tercero en la controversia, lo que no podía justificarse en relación con cuestiones ajenas al ámbito de interpretación del tratado. Se hizo una distinción con el párrafo 1, por el cual, según se dijo, las partes en el tratado que no eran litigantes se podían ver directamente afectadas por las cuestiones relativas a la interpretación del tratado, razón por la cual en ese párrafo el tribunal arbitral debería mantener la facultad para invitar a hacer presentaciones a partes no litigantes.

70. Tras deliberar al respecto, el Grupo de Trabajo convino en que se suprimiera la facultad del tribunal arbitral enunciada en el párrafo 2 para invitar a hacer presentaciones a partes en el tratado que no fueran litigantes. Se encomendó a la secretaría que redactara un nuevo texto en el que se reflejara esa decisión. Se aclaró que el propósito de la decisión de suprimir el texto relativo a ese punto no era que se viera afectada ninguna de las facultades de que el tribunal pudiera gozar por otras razones en virtud del reglamento de arbitraje o de otras disposiciones.

Otras cuestiones

71. El Grupo de Trabajo también convino en que podría sustituirse la palabra “aceptar”, utilizada en los párrafos 1 y 2 del artículo 6, por la palabra “permitir” en aras de la claridad y, además, para mantener la coherencia del texto con el párrafo 3 del artículo 5.

Párrafo 3

72. El Grupo de Trabajo examinó el párrafo 3 del artículo 6 y lo aprobó sin modificaciones en la forma enunciada en el párrafo 37 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169.

Párrafo 4

73. El Grupo de Trabajo examinó el párrafo 4 del artículo 6 y lo aprobó sin modificaciones en la forma enunciada en el párrafo 37 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169.

Párrafo 5

74. Conforme a la propuesta aceptada en relación con el artículo 5, que figura en el párrafo 57 del presente documento, el Grupo de Trabajo convino en que se suprimiera la palabra “también” del texto de ese párrafo. Además, aceptó la sugerencia de introducir la palabra “razonable” después de la palabra “oportunidad” y dio instrucciones a la secretaría para que se introdujeran las modificaciones consiguientes en los demás párrafos del proyecto en que se utilizara el término “oportunidad”, cuando procediera.

75. Se convino en que la secretaría redactara un nuevo proyecto de párrafo 5 del artículo 6 en el que quedasen reflejados esos acuerdos.

5. Artículo 7 - Audiencias

76. El Grupo de Trabajo examinó el artículo 7, enunciado en el párrafo 41 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169.

77. En relación con el párrafo 1 del artículo 7 surgió la duda de si entre los motivos permitidos para celebrar las audiencias, o parte de ellas, en privado y no en público había algunos otros además de los enunciados en los párrafos 2 o 3 del artículo 7. Al respecto, el Grupo de Trabajo también consideró la posibilidad de que las audiencias públicas fuesen la regla y no la excepción.

78. Se expresaron las siguientes opiniones a favor de limitar la discrecionalidad del tribunal en lo que respecta a las cuestiones mencionadas en los párrafos 2 y 3: que se corría el riesgo de que toda otra facultad discrecional fuese ambigua e indefinida, dejando al tribunal expuesto a las presiones de las partes, con lo que se pondría en peligro el principio de la transparencia; que en el párrafo 2 se preveían las excepciones a la norma de la transparencia establecidas en el artículo 8 y que, a diferencia del párrafo 3 del artículo 7, no había ninguna razón para otorgar al tribunal una facultad discrecional más amplia, que en los instrumentos de las Naciones Unidas deberían reflejarse los valores de los derechos humanos y la libertad de expresión y, en consecuencia, que toda excepción a la norma de la transparencia debería establecerse dentro de límites muy restringidos a fin de no

crear una discrecionalidad indefinida que quebrantara esos principios. Tras un debate, se convino en que no debía haber una discrecionalidad indefinida, y las deliberaciones se centraron en la cuestión de si las audiencias públicas debían ser la regla y no la excepción.

79. Se expresó cierto apoyo a la propuesta de que una parte litigante pudiese vetar unilateralmente una audiencia pública, si así lo deseaba. En apoyo de la propuesta, se señaló que era necesario disponer de una facultad de veto para salvaguardar la debida protección de la seguridad nacional y de la información confidencial, así como debido a problemas relacionados con la politización de las controversias. Se indicó también que las audiencias públicas podrían no funcionar desde el punto de vista logístico, y que en los párrafos 2 y 3 no se preveía nada para disipar esa preocupación, y también que deberían tenerse en cuenta las posibles consecuencias económicas de las audiencias públicas.

80. Algunas delegaciones expresaron su preferencia por recurrir, como regla supletoria, al párrafo 3 del artículo 28 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, según el cual las audiencias en los arbitrajes comerciales se celebraban a puerta cerrada, a menos que las partes acordaran lo contrario. Se observó que resultaba difícil ver de qué manera ese criterio favorecería el mandato del Grupo de Trabajo de promover la transparencia.

81. Se sugirió volver a examinar las cuestiones que planteaba el párrafo 1 del artículo 7, después de que el Grupo de Trabajo examinara el artículo 8, que tenía por objeto abordar las excepciones a la norma de la transparencia.

82. Tras un debate, se expresó considerable apoyo al principio de que, con arreglo al reglamento, la norma preestablecida seguiría siendo la de que las audiencias serían públicas, a reserva únicamente de las excepciones mencionadas en los párrafos 2 y 3, si bien algunas delegaciones apoyaron la opinión de que las partes deberían tener el derecho unilateral a pedir que las audiencias fueran en privado. Se formuló la pregunta de si el apoyo tan considerable expresado a favor del principio arriba indicado equivalía a un consenso. A fin de poder pasar a la segunda lectura, se acordó en última instancia seguir examinando el párrafo 1 del artículo 7 en deliberaciones ulteriores.

Párrafo 2

83. Tras las deliberaciones correspondientes, el Grupo de Trabajo convino en que se retiraran los corchetes de la expresión “de carácter confidencial o delicado” y, a reserva de las deliberaciones sobre el artículo 8, que se reseñan más adelante en el párrafo 90, en que se suprimieran las palabras “o delicado”. Consideró, por lo demás, que el artículo 7, párrafo 2, debía conservarse en la forma enunciada en el párrafo 41 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169.

Párrafo 3

84. Hubo amplio acuerdo en que en la segunda línea del párrafo 3 se suprimieran las palabras “derecho de”, dado que las disposiciones logísticas se referían al acceso y no al derecho de acceso.

85. También se sugirió que al final del párrafo se añadiera la palabra “inesperados” después de las palabras “motivos logísticos” con objeto de impedir

que se dispusiera de antemano la celebración de audiencias en privado únicamente por motivos logísticos que podrían o deberían haberse previsto. Esa sugerencia no obtuvo apoyo.

86. Se planteó una duda en relación con la definición de “audiencias” con objeto de que el párrafo 3 fuera suficientemente claro con respecto a las clases de audiencias a las que se daría acceso al público y que el tribunal facilitaría. Se indicó que, por principio, las audiencias siempre deberían ser públicas cuando en ellas se abordaran cuestiones sustantivas (por ejemplo, audiencias relativas a cuestiones jurisdiccionales y audiencias en las que se escucharan declaraciones de testigos o de peritos o argumentos orales), pero no cuando se trataran simples cuestiones de procedimiento.

87. Se señaló que tal vez fuera preciso utilizar apropiadamente el término “audiencia”, o sea, solo en el sentido de que no incluía simples deliberaciones de procedimiento. Se indicó que en el artículo 17, párrafo 3, del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y en el artículo 24, párrafo 1, de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional figuraban textos que podrían incorporarse al proyecto de reglamento a efectos de vincular el significado que allí se daba a las audiencias con el que tenían en el proyecto de reglamento.

88. El Grupo de Trabajo convino en que se retuviera el párrafo 3 del artículo 7, según figuraba en el párrafo 41 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169, con la modificación introducida en el párrafo 84 *supra* y la adición de un texto que reflejara el punto planteado en el párrafo 87 *supra*.

6. Artículo 8 - Excepciones a la norma de la transparencia

Primer subtítulo

89. El Grupo de Trabajo examinó el artículo 8 cuyo texto figura en el párrafo 45 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169.

90. Se expresaron diversas opiniones con respecto a cuál de las palabras que iban entre corchetes en el primer subtítulo convendría conservar para calificar el término “información”. Tras deliberar al respecto, se convino en que el primer subtítulo del artículo 8 fuese “Información confidencial o protegida”, por considerarse que era el que mejor expresaba el contenido de la disposición. Se convino también en que la secretaría introdujese las modificaciones consiguientes necesarias en el resto del texto del proyecto de reglamento con objeto de armonizarlo con esa formulación.

Párrafos 1 a 9

91. Se opinó que el criterio de redacción del artículo 3 era demasiado detallado, y se corría el riesgo de reglamentar excesivamente las facultades del tribunal arbitral, sin enumerar, al mismo tiempo, toda circunstancia que pudiese surgir.

92. En consecuencia, se sugirió una formulación más flexible y sencilla a fin de permitir que el tribunal arbitral adaptara su procedimiento a las circunstancias del caso. Sobre esa base, se presentó al Grupo de Trabajo un proyecto revisado del artículo 8 (el “proyecto de propuesta”).

93. El Grupo de Trabajo consideró la posibilidad de seguir examinando el artículo 8, párrafos 1 a 9, sobre la base del proyecto de propuesta. Se sugirió que

el Grupo volviera, en cambio, a examinar el proyecto de artículo 8 enunciado en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169. Esa propuesta no recibió apoyo. En consecuencia, el proyecto de propuesta sirvió de base para seguir examinando el artículo 8, párrafos 1 a 9 (con excepción del apartado 2) c), que se examinó por separado, en la forma en que figuraba en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169).

94. El texto del proyecto de propuesta era el siguiente:

“Proyecto de artículo 8 - Excepciones a la norma de la transparencia

Información confidencial o protegida

1. La información confidencial o protegida, como se define más adelante en el párrafo 2 y se determina en cumplimiento de las disposiciones a que se hace referencia en los párrafos 3 y 4, no se pondrá a disposición del público ni de las partes que no sean litigantes con arreglo a los artículos 2 a 7.
2. La información confidencial o protegida consiste de:
 - a) Información comercial confidencial;
 - b) Información que no debe ponerse a disposición del público, con arreglo al tratado;
 - c) Información que no debe ponerse a disposición del público, con arreglo a cualquier ley o reglamento que, a juicio del tribunal arbitral, sea aplicable a la revelación de esa clase de información.
3. El tribunal arbitral adoptará disposiciones para impedir que cualquier información confidencial o protegida se haga pública, aplicando, en consulta con las partes, procedimientos para declararla confidencial o protegida y suprimirla, o celebrando audiencias en privado de conformidad con el párrafo 2 del artículo 7. El tribunal arbitral decidirá, previa consulta con las partes, si determinada información es confidencial o protegida.
4. Si el tribunal arbitral determina que esa información no debe suprimirse de un documento, o que no debe impedirse que un documento se haga público, la parte litigante, la parte no litigante o el tercero que haya presentado el documento podrá i) volver a presentar el documento en una forma que se adecue a lo determinado por el tribunal, o ii) retirar el documento o una parte de este de las actuaciones arbitrales.”

Párrafo 1 del proyecto de propuesta

95. Se sugirió que se actualizaran las remisiones a párrafos que figuraban en el párrafo 1 y se encomendó a la secretaría que realizara esa tarea, además de introducir toda otra modificación consiguiente de numeración o de remisiones a párrafos.

96. Por lo demás, se consideró aceptable el texto del párrafo 1 del proyecto de propuesta y se decidió conservarlo en la forma en que allí se enunciaba.

Párrafo 2 del proyecto de propuesta

97. Tras deliberar al respecto, se convino en conservar el encabezamiento del párrafo 2 con la formulación que tenía e introducir las modificaciones consiguientes

necesarias para armonizarlo con el título enmendado del artículo 8, enunciado arriba en el párrafo 90.

Párrafos 2 a) y 2 b) del proyecto de propuesta

98. Se convino en que se añadiera la palabra “o” después del apartado b) a fin de aclarar que las categorías enumeradas en el párrafo 2 eran alternativas.

99. Se planteó una duda con respecto al significado de la expresión “información comercial confidencial” en el párrafo 2 a) y se señaló que se requería una definición de esa expresión en el reglamento, o una lista de ejemplos ilustrativos. También se sugirió que se añadiera la palabra “delicada” después de la palabra “confidencial”. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en mantener el artículo 8 2) a) como había sido redactado.

100. Se convino además en que el texto del apartado b) del proyecto de propuesta era aceptable y se debía conservar en la forma en que allí se enunciaba.

Párrafo 2 c) del documento A/CN.9/WG.II/WP.169

101. El Grupo de Trabajo examinó el texto del artículo 8 2) c) que figura en el párrafo 45 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169.

102. Se formuló la propuesta de suprimir toda referencia a la legislación de la parte litigante, que, según se dijo, menoscaba la facultad discrecional del tribunal arbitral para determinar la ley aplicable. En respuesta, se expresaron preocupaciones de que una propuesta de esa índole no proporcionaba orientación suficiente, en particular a un demandado, en cuanto a si las decisiones del tribunal arbitral podrían ponerlo en situación de quebrantar su propia legislación. Tras un debate, se propuso una solución de avenencia, que haría obligatoria la aplicación de la legislación del demandado a la revelación de información por ese demandado, en tanto que toda la demás información quedaría sujeta a la determinación sobre conflicto de leyes por el tribunal. A ese respecto, el Grupo de Trabajo examinó una propuesta presentada conjuntamente por varias delegaciones relativa al artículo 8 2) c) (el “proyecto de propuesta”): “Información que no debe ponerse a disposición del público, en el caso de la información del demandado, con arreglo a la legislación del demandado, y en el caso de información de otro tipo, con arreglo a cualquier ley o reglamento que el tribunal arbitral determine aplicable a la revelación de ese tipo de información”.

103. El Grupo de Trabajo no llegó a ningún acuerdo en relación con el proyecto de propuesta. Se expresó la opinión de que la legislación de la parte que presentara la información debería aplicarse obligatoriamente a esa información. Esa opinión no recibió apoyo. Se expresaron opiniones en el sentido de que el proyecto de propuesta tranquilizaría a los países en desarrollo que tenían preocupaciones, entre otras cosas, de que los intereses de seguridad nacional quedaran suficientemente protegidos. Se expresaron otras opiniones en el sentido de que la disposición se prestaba a abuso y debilitaría el objetivo del reglamento; y, en concreto, de que la idea de que un Estado se viera obligado a aplicar su legislación nacional en relación con información que suministrara permitiría a un Estado eludir el objeto del reglamento mediante la introducción de legislación que impidiera la revelación de toda información en las controversias entre inversionistas y Estados. En respuesta, se expresó apoyo unánime al planteamiento de que no era aceptable que un Estado

adoptara el reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia y utilizara luego su legislación interna para minar el espíritu (o la letra) de ese reglamento.

104. Tras nuevas deliberaciones, se dijo que se habían expresado tres opiniones, en forma de propuestas distintas: i) una propuesta (expuesta arriba en el párrafo 102) con arreglo a la cual se otorgaría al tribunal facultad discrecional para realizar un análisis de conflicto de leyes respecto de toda la información; ii) el “proyecto de propuesta” recogido en el párrafo 102, con arreglo al cual se remitía al tribunal a la legislación del demandado respecto de la información del demandado, y a un análisis sobre conflicto de leyes respecto de toda la demás información; y iii) una propuesta con arreglo a la cual se daba al tribunal orientación de que, en su análisis sobre conflicto de leyes respecto de cuestiones relacionadas con la información del demandado, debería tener particularmente en cuenta la legislación del demandado. Se pidió a la secretaría que incluyera esas tres opciones en proyectos posteriores para que el Grupo de Trabajo las siguiera examinando.

Párrafo 2 bis)

105. Se presentó al Grupo de Trabajo el nuevo texto siguiente, propuesto como artículo 8 (2) *bis*): “Nada de lo dispuesto en el presente reglamento obligará a una parte a facilitar (al público) información cuya revelación estime que impediría la aplicación de la ley o sería contraria al interés público o a sus intereses de seguridad esenciales”.

106. Se dijo que esta disposición no estaba concebida como una nueva excepción en virtud del artículo 8, sino que era una cuestión que un Estado podría determinar para sí. Varias delegaciones expresaron su oposición al texto propuesto argumentando que negaría la propia meta de transparencia en que se sustentaba el reglamento y sería contraria a la orientación que la Comisión había impartido al Grupo de Trabajo. Se dijo que expresiones como “impediría la aplicación de la ley” y “sería contraria al interés público” eran demasiado amplias y que prácticamente se les podría dar cualquier significado a fin de justificar la retención de información. A ese respecto, se señaló que el mandato del Grupo de Trabajo se basaba en la premisa de que la propia transparencia beneficiaba el interés público.

107. Se declaró además que la protección de dicha información debería figurar en las leyes nacionales, y con frecuencia ya figuraba, así como en tratados celebrados por el Estado, y que no había ninguna justificación para que el reglamento ofreciera en efecto un nivel adicional de protección. Varias delegaciones objetaron la idea de que el propio Estado decidiera qué información retener, lo cual se consideraba como parte de la competencia del tribunal.

108. Se sugirió que, dado que la información de que se trataba estaría sujeta a la legislación interna de un Estado, la cuestión se abordara en el marco del artículo 8 2) c).

109. En respuesta, se señaló que los tratados de inversiones concertados antes de la fecha de aprobación del reglamento sobre la transparencia (“tratados existentes”) no siempre contenían disposiciones que protegieran esa información y que era importante que hubiera un equilibrio en el reglamento sobre la transparencia. Se declaró también que, incluso debido a que las deliberaciones sobre el artículo 8 2) c) aún no habían concluido, no estaba claro que la ley de un Estado parte litigante ofreciera la protección necesaria.

Párrafo 3

110. El Grupo de Trabajo examinó un segundo proyecto de propuesta sobre el artículo 8 3), tras haber llegado a acuerdo de que se debería establecer con más claridad la mecánica del nexo entre el artículo 3 y el artículo 8 (véase el párrafo 32 *supra*), y que se abordará la cuestión de la rapidez con que se deberían facilitar los documentos (el “segundo proyecto de propuesta” sobre el artículo 8). El segundo proyecto de propuesta dice lo siguiente: “3. El tribunal arbitral, en consulta con las partes, adoptará disposiciones para impedir que cualquier información confidencial o protegida se haga pública, incluso aplicando, según proceda i) plazos en los que una parte, una parte no litigante o un tercero comuniquen que un documento contiene información confidencial o protegida, ii) procedimientos para declarar con rapidez que la información de que se trate es confidencial o se halla protegida y suprimirla de dichos documentos, y iii) procedimientos para celebrar audiencias en privado, en la medida en que ello se prevea en el artículo 7, párrafo 2. El tribunal arbitral decidirá, previa consulta con las partes, si determinada información es confidencial o protegida”.

111. Se expresó amplio apoyo al segundo proyecto de propuesta, con varias modificaciones menores. Se acordó que:

a) En el inciso i), se sustituyeran las palabras “un documento contiene información confidencial o protegida” por las palabras “desea proteger dicha información en un documento”;

b) En la última frase, se sustituyera la palabra “decidirá” por la palabra “determinará”, y se encomendó a la secretaría que velara por la utilización sistemática de la palabra correcta en todo el proyecto de reglamento;

c) La secretaría velara por que se utilizaran correctamente los términos “partes” y “partes litigantes” en todo el proyecto;

d) Se sustituyeran las palabras “se haga pública” por las palabras “se ponga a disposición del público” y se agregara a continuación la expresión “ni de las partes que no sean litigantes”, a fin de asegurar la coherencia con el párrafo 1; y

e) Se substituyera la palabra “prevea” de la última frase (“se prevea en el artículo 7”) por la palabra “requiera”.

112. El Grupo de Trabajo acordó conservar el segundo proyecto de propuesta como figura en el párrafo 110 y con las modificaciones señaladas en el párrafo 111.

Párrafo 4

113. Se expresaron inquietudes respecto del párrafo 4 del proyecto de propuesta que figura en el párrafo 94, y concretamente en el sentido de que en ese proyecto de propuesta se pasaba por alto la circunstancia en la cual una parte obligada por el tribunal arbitral a presentar un documento podía retirarlo posteriormente por motivos de confidencialidad. Hubo acuerdo en que el párrafo 4 estaba destinado a aplicarse únicamente en los casos en que una parte hubiera presentado voluntariamente un documento.

114. A fin de aclarar esa intención, se propuso la redacción siguiente: “4. Si el tribunal arbitral determina que esa información no debe suprimirse de un documento, o que no debe impedirse que un documento se haga público, la parte

litigante, la parte no litigante o el tercero que haya presentado voluntariamente el documento para el archivo podrá retirar el documento o una parte de este de las actuaciones arbitrales”.

115. Se llegó a un amplio acuerdo respecto de esa redacción, con dos reservas. En primer lugar, se señaló que esa formulación permitiría a la parte que presentara un documento para el archivo, retirar una parte de el que ella misma considerase confidencial (por razones lícitas o improcedentes), y que ello podría distorsionar el significado del documento en su conjunto. A modo de respuesta, se señaló que aunque con esa formulación no se abordaba directamente el asunto, el tribunal arbitral podía hacer frente a esa conducta en el contexto de las actuaciones, por ejemplo haciendo inferencias negativas o, en el caso de las pruebas, ejerciendo su facultad discrecional para disponer que no se publicase el documento. En segundo lugar, se señaló que si ambas partes convenían en la confidencialidad de un documento, correspondía a ellas, y no al tribunal, determinar si no se daba a conocer el documento al público. Esa sugerencia no recibió apoyo en el contexto del párrafo 4, y se señaló que dicho enfoque debilitaría la custodia del reglamento por el tribunal.

116. Tras un debate, se acordó conservar el párrafo 4 en la forma en que figura en el párrafo 114.

117. Con respecto a la segunda cuestión señalada antes en el párrafo 115, posteriormente se formuló la propuesta de insertar en el artículo 8 2) un nuevo apartado d) que dijera: “información que ambas partes litigantes acuerden no poner a disposición del público, a menos que ello atente contra el interés público”. Se expresó cierto apoyo a esa propuesta, aunque algunas delegaciones se opusieron resueltamente a la sugerencia, por lo que se convino en seguir examinándola durante la tercera lectura del reglamento.

Párrafos 10 y 11 - Integridad de las actuaciones arbitrales

Párrafo 10

118. Tras un debate, se acordó mantener la redacción de ese párrafo según figuraba en el párrafo 45 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169, con los cambios consiguientes de numeración como resultado de las modificaciones del artículo 8 expuestas anteriormente.

Párrafo 11

119. Se acordó mantener la redacción de ese párrafo según figuraba en el párrafo 45 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169, con los cambios consiguientes de numeración como resultado de las modificaciones del artículo 8 expuestas anteriormente.

7. Artículo 9 - Archivo de la información puesta a disposición del público

120. El Grupo de Trabajo examinó el artículo 9, enunciado en el párrafo 1 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1. Se expresaron opiniones a favor de la opción 2, argumentando que de esa manera en un procedimiento arbitral determinado habría un solo órgano administrativo que se encargara de la aplicación tanto del reglamento sobre la transparencia como del procedimiento de arbitraje. El Grupo de Trabajo no llegó a un consenso respecto de cual de las dos opciones allí

señaladas era preferible, y, por lo tanto, la decisión se aplazó hasta un futuro período de sesiones.

121. Sin embargo, se convino, en principio, en que si el Grupo de Trabajo adoptaba en último término la opción 1, la CNUDMI sería la institución depositaria preferente para ocuparse del archivo, si tuviera la capacidad de asumir esa función. Se convino también en que, si se designaba a varias instituciones para encargarse del archivo, conforme a la opción 2, debería haber un sitio web central, de cuya creación se encargara preferiblemente la CNUDMI, que sirviera como centro de información para vincular la función de archivo de esas instituciones.

122. Además, se encomendó a la CNUDMI la tarea de establecer enlaces con otras instituciones arbitrales, a fin de evaluar mejor el costo y otras repercusiones de asumir la función de administrar el archivo, y de que informara al Grupo de Trabajo al respecto en su período de sesiones siguiente.

8. Observaciones generales sobre segunda lectura del proyecto de reglamento sobre la transparencia

123. Al comienzo del cuarto día del período de sesiones, las cuestiones que el Grupo de Trabajo aún tenía por examinar en su segunda lectura del proyecto de reglamento sobre la transparencia podían resumirse de la siguiente manera: i) un nuevo proyecto de propuesta en relación con el artículo 3, párrafo 4, y el artículo 8, párrafo 3, que se consideraban interrelacionados; ii) un nuevo proyecto de propuesta relativo al artículo 8, párrafo 2, apartado c); iii) un proyecto de propuesta de un nuevo párrafo, que posiblemente se titularía artículo 8, párrafo 2 *bis*); iv) el artículo 8, párrafo 4; v) el artículo 9; y vi) dos cuestiones independientes relacionadas con a) la posibilidad de establecer un plazo para limitar cronológicamente las solicitudes de los terceros (tanto de documentos como de presentación de documentos) en los artículos 3 y 5, y b) la manera en que se sufragarían los gastos relacionados con el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia.

124. Así pues, quedaría para la tercera lectura el examen de las cuestiones pendientes en el artículo 1 (Ámbito de aplicación); el artículo 6, párrafo 1, en particular, si deberían utilizarse las palabras “podrá aceptar” o “aceptará”, y el artículo 7, párrafo 1, en relación con las audiencias públicas.

Presentaciones de terceros y solicitudes de acceso a documentos por terceros

125. Como se señaló ya en el párrafo 123 el Grupo de Trabajo convino en examinar el número y el momento de las presentaciones de terceros previstas en los artículos 3 y 5. No recibió apoyo la propuesta de crear una regla concreta destinada a fijar plazos durante los cuales las partes podrían tener acceso a los documentos con arreglo al artículo 3 y realizar presentaciones con arreglo al artículo 5. Tampoco se apoyó la propuesta de limitar el número de presentaciones de terceros. En cambio, se convino en que la gestión de las actuaciones debía seguir sujeta a la discreción del tribunal arbitral.

Gastos

126. En respuesta a varias preguntas generales respecto de la forma de sufragar los gastos de los procedimientos de transparencia, el Grupo de Trabajo examinó la cuestión de los gastos como asunto independiente.

127. Se señaló que había por lo menos cuatro categorías de gastos relacionados con las medidas de transparencia: i) los gastos de la presentación de los documentos en el sitio web del registro; ii) los gastos de las audiencias públicas; iii) los gastos relacionados con la participación de terceros (es decir, los gastos legales que entrañaba responder a los documentos presentados); y iv) los gastos de los árbitros.

128. Además, se expresó la opinión de que dichos gastos eran una parte necesaria de la aplicación de procedimientos de transparencia para promover el mandato otorgado por la Comisión al Grupo de Trabajo.

129. Se sugirió que el reglamento previera la posibilidad de que el tribunal impusiera el pago de costas a todo tercero que presentara documentos insustanciales en una actuación arbitral. Se señaló que un tercero podía someterse a la jurisdicción de un tribunal en el momento de ser aceptado como “tercero” (según se definía este de conformidad con el artículo 5). En respuesta a esa sugerencia, se señaló que era improbable que el tribunal y las partes respondieran a una presentación insustancial (con lo que se evitarían gastos), pero que, además, la posibilidad de que se impusiera el pago de costas a un tercero insolvente inhibiría, con toda probabilidad, su participación en el proceso de arbitraje, lo que sería contrario al interés público de la transparencia.

130. Se formuló otra propuesta en el sentido de que en el reglamento se abordara la cuestión de los gastos de permitir el acceso de terceros a las pruebas, ya que se consideraba justo que sufragara esos gastos la parte solicitante y no las partes litigantes. Tras un debate, se aclaró que los gastos, en este sentido, quedaban limitados a la presentación de los documentos a la parte (por ejemplo, los gastos de fotocopiado o envío) y no al proceso de preparación de los documentos (por ejemplo, la supresión de texto) para su divulgación. Se observó que era legítimo preocuparse por los gastos de esos procesos, pero que ello podía resultar conflictivo con la finalidad general de la transparencia, ya que los gastos no deberían ser un factor disuasivo de la participación pública en las actuaciones. Se puso en tela de juicio la imparcialidad de una disposición por la que se impondría el pago de costas a la primera persona que solicitara acceso a documentos que se pondrían luego a disposición del público general. Tras un debate, se convino en que cuando terceros solicitaran acceso a los documentos solo se les exigiera sufragar los gastos administrativos de ese acceso (como los de fotocopiado, envío o gastos similares) y se encomendó a la secretaría que, sobre esta base, redactara un texto que reflejara ese acuerdo con miras a someterlo al examen del Grupo de Trabajo.

9. Artículo 1 - Ámbito de aplicación

131. En relación con el ámbito de aplicación del reglamento sobre la transparencia, el Grupo de Trabajo examinó el artículo 1 con el propósito de adelantar las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre dicho artículo con antelación a su próximo período de sesiones. Se presentaron al Grupo de Trabajo dos nuevos proyectos de propuesta, con el objetivo expreso de englobar el criterio expuesto en el párrafo 54 del documento A/CN.9/741.

132. Se acordó fusionar esas dos propuestas, incluyendo entre corchetes el texto de las formulaciones divergentes, de modo que las dos propuestas pudieran examinarse como una sola en un período de sesiones futuro. La propuesta fusionada decía lo siguiente: “artículo 1 -Ámbito de aplicación del reglamento sobre la transparencia

1. El presente Reglamento se aplicará a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado que establezca la protección de las inversiones o los inversionistas (“el tratado”) celebrado después de [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia], a menos que las partes en el tratado hayan acordado otra cosa.

2. Con respecto a i) los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado celebrado antes de [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia] y ii) los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados con arreglo a otros reglamentos de arbitraje o con carácter especial, el presente Reglamento [solamente] se aplicará [si] [a reserva de que]: a) la partes litigantes [conviene] [convengan] en su aplicación respecto de ese arbitraje; o, b) las partes en el tratado, o en el caso de un tratado multilateral, el Estado del que el inversionista sea ciudadano y el demandado hayan convenido [en un instrumento adoptado] [en la aplicación del presente Reglamento] después de [fecha de la entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia] [en un instrumento adoptado]”.

133. Esa propuesta contenía también un proyecto de nuevo artículo 1 párrafo 4) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (versión revisada en 2010), a fin de articular la vinculación entre el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y el proyecto de reglamento sobre la transparencia, sin hacer formalmente del reglamento sobre la transparencia parte del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI o un anexo de ese Reglamento, de modo que el reglamento sobre la transparencia se pueda aplicar a arbitrajes realizados con arreglo a reglamentos distintos del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El proyecto de nuevo artículo 1, párrafo 4), del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (versión revisada en 2010) dice así: “4. En relación con los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados con arreglo a un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas, el presente Reglamento de Arbitraje incluye el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia [con las modificaciones que se introduzcan de tiempo en tiempo], a reserva de lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia”.

134. Se convino en que la propuesta recién enunciada en los párrafos 132 y 133 se sometería a consideración del Grupo de Trabajo en su siguiente período de sesiones. La propuesta incluía también, a título de referencia, un diagrama que ilustraba la manera en que la propuesta afectaría el arbitraje relacionado con la CNUDMI (aunque no otros tipos de arbitraje institucional).

135. Se expresaron opiniones en el sentido de que no se debería obligar a las delegaciones a aceptar el reglamento sobre la transparencia ya fuese mediante una interpretación dinámica o de alguna otra manera, sino que siempre debería darse un consentimiento expreso. Según otras opiniones, donde se reconociera la interpretación dinámica de los tratados e incluso se aceptara como práctica corriente, no se debería privar a los Estados de dicha interpretación, en vista especialmente de que podría producir el efecto de facilitar los objetivos de la transparencia.

136. A ese respecto, se convino en que toda solución ofrecida con arreglo al artículo 1 no debería debilitar ninguna de las facultades discrecionales de que gozaran los tribunales por otras razones con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (versión revisada de 2010).

137. El Grupo de Trabajo invitó a los Estados a que revisaran sus tratados a fin de determinar si contenían referencias específicas al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, tales como “el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI en vigor en ese momento” o “el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI con las modificaciones que se introduzcan de tiempo en tiempo”.

138. Se declaró que quienes eran partidarios de la redacción sobre el ámbito de aplicación enunciada antes en los párrafos 132 y 133 reconocían también la importancia de garantizar la aplicación del reglamento sobre la transparencia a los tratados existentes y, por consiguiente, instaban al Grupo de Trabajo a que, al mismo tiempo que examinaba la formulación recogida en los párrafos 132 y 133, procediera sin demora a un examen de posibles mecanismos que permitieran su aplicación a los tratados existentes.

139. Se hizo hincapié asimismo en que el propio reglamento debería ofrecer normas claras y firmes sobre la transparencia y que el artículo 1 sería el mecanismo mediante el cual las partes podrían acordar si aplicaban o no el reglamento sobre la transparencia.

140. Con respecto a los tratados existentes, se hizo notar que varias delegaciones habían presentado una propuesta (que figuraba en el documento A/CN.9/WG.II/WP.174) de que en el reglamento sobre la transparencia no se estableciera ninguna norma o suposición respecto de su aplicación en virtud de los tratados existentes, sino que, por el contrario, esa aplicación quedara por determinar de conformidad con las normas internacionalmente aceptadas de interpretación de los tratados. Se dijo, en apoyo de ese criterio, que la aplicación del reglamento a los tratados existentes solo cuando las partes dieran su “aceptación expresa” de aplicar el reglamento mediante un acuerdo posterior (como se proponía en el párrafo 132) frustraría las expectativas razonables de los países que se proponían beneficiarse de las cláusulas dinámicas de sus tratados y enviaría un mensaje negativo con respecto a las bondades de la transparencia. En cambio, la aplicación presuntiva del reglamento sobre la transparencia en virtud del enfoque “de exclusión facultativa” respecto de tratados futuros haría llegar un mensaje convincente en favor de la transparencia y promovería la amplia utilización del reglamento sobre la transparencia.

141. Se convino, además, en dar a la secretaría el mandato de preparar i) el texto de un convenio sobre la transparencia en los arbitrajes, enablados en el marco de un tratado, entre inversionistas y Estados, a fin de incluir un proyecto de cláusula que permitiera formular una reserva a ese convenio, y ii) el texto de una declaración unilateral, para que el Grupo de Trabajo los examinaran en su 58º período de sesiones.

**B. Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales:
preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los
arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de
un tratado, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y
Conciliación en su 57º período de sesiones**

(A/CN.9/WG.II/WP.172)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-5
II. Proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	6-28
A. Contenido del proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	6-28
Artículo 1. Ámbito de aplicación	6-23
Artículo 2. Publicación de información tras el inicio de las actuaciones arbitrales	24-28

I. Introducción

1. En su 43º período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010), la Comisión recordó, respecto de la labor futura en materia de solución de controversias comerciales, la decisión adoptada en su 41º período de sesiones (Nueva York, 16 de junio a 3 de julio de 2008)¹ de que, una vez concluida la revisión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, se abordara, con carácter prioritario, el tema de la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado. La Comisión encomendó a su Grupo de Trabajo II la tarea de preparar una norma jurídica sobre ese tema².

2. En su 44º período de sesiones (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011), la Comisión reiteró el compromiso que había expresado en su 41º período de sesiones respecto de la importancia de asegurar la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado. Se confirmó que la cuestión de la aplicabilidad de la norma jurídica sobre la transparencia a los tratados de inversiones vigentes formaba parte del mandato del Grupo de Trabajo y era una cuestión que revestía un gran interés práctico, habida cuenta del gran número de tratados ya concertados³.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, Sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1)*, párr. 314.

² *Ibid.*, *Sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17)*, párr. 190.

³ *Ibid.*, *Sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17)*, párr. 200.

3. En su 45º período de sesiones (Nueva York, 25 de junio a 6 de julio de 2012), la Comisión reafirmó la importancia de garantizar la transparencia de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, reconocida en sus períodos de sesiones 41º y 44º, celebrados respectivamente en 2008 y 2011⁴, e instó al Grupo de Trabajo a que prosiguiera y concluyera su labor relativa a las normas sobre transparencia, para someterlas al examen de la Comisión, de preferencia en su próximo período de sesiones⁵.
4. En sus períodos de sesiones 53º (Viena, 4 a 8 de octubre de 2010) y 54º (Nueva York, 7 a 11 de febrero de 2011), el Grupo de Trabajo examinó las cuestiones de la forma, la aplicabilidad y el contenido de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado⁶. En su 55º período de sesiones (Viena, 3 a 7 de octubre de 2011), el Grupo de Trabajo concluyó la primera lectura del proyecto de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (incluido en el documento A/CN.9/WG.II/WP.166 y su adición)⁷. En su 56º período de sesiones (Nueva York, 6 a 10 de febrero de 2012), el Grupo de Trabajo inició la segunda lectura del proyecto de una norma jurídica sobre la transparencia (incluido en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169 y su adición)⁸.
5. De conformidad con las decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo en su 56º período de sesiones⁹, en la parte II de la presente nota figura un proyecto revisado de los artículos 1 y 2 del Reglamento sobre la Transparencia. Los artículos 3 a 8 del proyecto de reglamento sobre la transparencia se tratan en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169, mientras que el artículo 9, sobre la creación de un archivo de información puesta a disposición del público, se trata en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1. Las observaciones recibidas de instituciones de arbitraje sobre la interrelación entre el Reglamento sobre la Transparencia y sus normas institucionales figuran en el documento A/CN.9/WG.II/WP.173. En el documento A/CN.9/WG.II/WP.174 se reproduce una propuesta de los gobiernos sobre el párrafo 1 del artículo 1 del proyecto de reglamento sobre la transparencia.

⁴ *Ibid.*, Sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1), párr. 314; *ibid.*, Sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 200.

⁵ Informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 45º período de sesiones (*en preparación*).

⁶ Informes del Grupo de Trabajo sobre la labor realizada en sus períodos de sesiones 53º (A/CN.9/712) y 54º (A/CN.9/717).

⁷ Informe del Grupo de Trabajo sobre la labor realizada en su 55º período de sesiones (A/CN.9/736).

⁸ Informe del Grupo de Trabajo sobre la labor realizada en su 56º período de sesiones (A/CN.9/741).

⁹ *Ibid.*

II. Proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado

A. Contenido del proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado

Artículo 1. Ámbito de aplicación

6. Proyecto de artículo 1 (Ámbito de aplicación)

Párrafo 1) - Aplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia

“1. El presente Reglamento será aplicable a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con un tratado que prevea la protección de las inversiones o de los inversionistas (“el tratado”) cuando las partes en el tratado [o todas las partes en el arbitraje (las “partes litigantes”)] hayan convenido en su aplicación. En un tratado celebrado después del [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia], se presumirá que toda remisión que se haga en el tratado al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI incluye el Reglamento sobre la Transparencia, a menos que las partes en el tratado hayan convenido lo contrario, por ejemplo, remitiendo a una determinada versión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI [que no haga referencia al Reglamento sobre la Transparencia].”*

Párrafo 2) - Aplicación del Reglamento sobre la Transparencia por las partes litigantes

“2. En todo arbitraje en que sea aplicable el Reglamento sobre la Transparencia de conformidad con un tratado o con un acuerdo concertado por las Partes en ese tratado,

a) las [partes litigantes] [las partes en el arbitraje (las “partes litigantes”)] no podrán apartarse de ese reglamento mediante acuerdo o del modo que fuere, a menos que el tratado se lo permita;

b) en la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia, el tribunal arbitral, al margen de las facultades discrecionales que le confieren algunas disposiciones del presente Reglamento sobre la Transparencia, estará facultado para adaptar los requisitos de cualquier disposición concreta del presente Reglamento a las circunstancias del caso si ello resulta necesario para lograr en la práctica el objetivo de la transparencia del Reglamento.”

Párrafo 3) - Relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el reglamento de arbitraje aplicable

“3. Siempre que el Reglamento sobre la Transparencia sea aplicable, complementará cualquier otro reglamento de arbitraje aplicable. Cuando exista un conflicto entre el Reglamento sobre la Transparencia y

las normas de arbitraje aplicables, prevalecerá el Reglamento sobre la Transparencia.”

Párrafo 4) - Relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el derecho aplicable

“4. Cuando una norma del Reglamento esté en conflicto con una disposición del derecho aplicable al arbitraje que las partes no puedan derogar, prevalecerá esa disposición.”

Párrafo 5) - Discrecionalidad del tribunal arbitral

“5. Cuando el Reglamento establezca que el tribunal arbitral tendrá facultades discrecionales, en el ejercicio de tales facultades el tribunal arbitral tendrá en cuenta: a) el interés público en la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado y en el proceso arbitral en particular; y b) el interés de las partes litigantes en que la controversia se resuelva de manera justa y eficaz.”

Nota a pie de página del párrafo 1 del artículo 1:

*“*A los fines del presente Reglamento, por “tratado que prevea la protección de las inversiones o de los inversionistas” se entenderá en sentido amplio todo acuerdo concertado entre Estados u organizaciones de integración regional, incluidos asociaciones de libre comercio, acuerdos de integración económica, acuerdos marco de comercio o inversiones o de cooperación y tratados bilaterales y multilaterales de inversiones, que contengan disposiciones sobre la protección de las inversiones o los inversionistas y su derecho a recurrir al arbitraje entre inversionistas y Estados.”*

Observaciones generales

Párrafo 1) - Aplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia

7. En su 56° período de sesiones, el Grupo de Trabajo encomendó a la secretaría la preparación de una versión revisada del párrafo 1 del artículo 1 (A/CN.9/741, párrs. 54 y 57). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó dos opciones con relación a la aplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia. Según la primera opción, la solución de exclusión, el Reglamento sobre la Transparencia se incorporaría al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010) (“el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010”) y se aplicaría como complemento del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI en el marco de los tratados de inversiones que previeran procedimientos regidos por el Reglamento de Arbitraje, a menos que el tratado dispusiera la inaplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia (A/CN.9/741, párr. 14). En lo que respecta a esa opción, se debatió si el Reglamento sobre la Transparencia también se aplicaría a los arbitrajes derivados de los tratados ya existentes, a modo de “referencia dinámica”, lo que durante el debate fue denominado “interpretación dinámica” por el Grupo de Trabajo, en el sentido de que, a partir de la fecha de adopción del Reglamento sobre la Transparencia, cualquier referencia al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI en un tratado de inversiones, incluidos los tratados de inversiones vigentes, también incorporaría el Reglamento sobre la Transparencia (A/CN.9/741, párrs. 20 y 42).

En virtud de la segunda opción, la solución de adhesión, el Reglamento sobre la Transparencia solo sería aplicable cuando las Altas Partes Contratantes (denominadas “Partes”) en un tratado de inversiones consintieran expresamente en su aplicación (A/CN.9/741, párr. 14).

8. Las posiciones expresadas en ese período de sesiones diferían en cuanto a i) si era preferible la solución de adhesión o la de exclusión; y ii) si habría que dejar abierta la posibilidad de una interpretación dinámica de los tratados ya existentes. Se expresaron opiniones en favor de ambas opciones, siendo la posición mayoritaria favorable a la primera opción (A/CN.9/741, párr. 55).

9. De conformidad con las instrucciones del Grupo de Trabajo para reformular el proyecto de párrafo 1 del artículo 1 teniendo en cuenta las deliberaciones celebradas en el 56° período de sesiones (A/CN.9/741, párrs. 54 y 57), la primera frase del proyecto de párrafo 1 establece el principio general de derecho internacional público que afirma que las Partes únicamente estarán sujetas a un conjunto externo de normas si así lo deciden. Con el fin de aclarar que ninguna interpretación dinámica de los tratados de inversiones podrá dar lugar a la aplicación inmediata del Reglamento sobre la Transparencia en el contexto de los tratados vigentes, se exige que las Partes manifiesten su acuerdo de forma expresa para que el Reglamento pueda aplicarse. La segunda frase del párrafo 1 se refiere a los tratados celebrados con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Reglamento. En ella se establece una presunción a favor de la aplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia. Se pidió a las delegaciones que tenían problemas para aceptar ese enfoque (A/CN.9/741, párr. 59) que coordinaran sus esfuerzos y transmitieran a la secretaría sus propuestas de redacción al respecto a fin de someterlas al examen del Grupo de Trabajo (véase el documento A/CN.9/WG.II/WP.174).

10. El Grupo de Trabajo podrá, si lo estima oportuno, estudiar la posibilidad de incluir una referencia a “todas las partes litigantes” en el párrafo 1 del artículo 1, para que quede claro que las partes litigantes pueden aplicar el Reglamento sobre la Transparencia.

Efectos del Reglamento sobre la Transparencia como reglamento independiente y como apéndice del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 y de los tratados existentes

11. En su 56° período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la secretaría que le proporcionara un análisis de las repercusiones que tendría la presentación del Reglamento sobre la Transparencia en forma de apéndice al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, o como texto independiente. Si el Reglamento sobre la Transparencia se convirtiera en un apéndice de dicho Reglamento de Arbitraje, habría tres reglamentos de arbitraje de la CNUDMI: el Reglamento de Arbitraje de 1976, el Reglamento de Arbitraje de 2010 y el Reglamento de Arbitraje de 2013 o 2014 (el “nuevo Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI”).

a. Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI

12. Si el Reglamento sobre la Transparencia se convirtiese en un apéndice del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010, ello constituiría una modificación del Reglamento, y tendría por efecto un nuevo Reglamento de Arbitraje (véase el párrafo 11). Así por ejemplo, el artículo 1 2) del Reglamento de Arbitraje de

la CNUDMI de 2010 tendría que modificarse, con el fin de aclarar la relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Otras disposiciones del Reglamento de Arbitraje de 2010 que se verían afectadas, esto es, modificadas o complementadas por la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia, serían los artículos 3, 4, 17 1), 28 3) y 34 5) (véase también el documento A/CN.9/WG.II/WP.169, párrs. 25 a 34).

13. El Grupo de Trabajo podrá, si lo estima oportuno, estudiar si el hecho de incluir el Reglamento sobre la Transparencia como apéndice del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 modificaría su aplicabilidad genérica, dado que la modificación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 constituiría, de hecho, un conjunto de normas de arbitraje específicas aplicables a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado de inversiones. Si el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 se modificase en ese sentido, se plantearía la cuestión de si habrían de añadirse otras disposiciones específicas sobre inversiones a ese nuevo conjunto de normas. Podrían surgir confusiones entre el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976 y el de 2010 como reglamentos de arbitraje genéricos y el nuevo Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

14. Otro factor que el Grupo de Trabajo podrá considerar, si lo estima oportuno, a la hora de fundamentar su decisión respecto de la forma del Reglamento sobre la Transparencia es el riesgo de que las instituciones arbitrales no se sientan inclinadas a promover la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia, si éste se incluye en un apéndice al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010. En tal caso, las instituciones de arbitraje tendrían que aplicar ineludiblemente un conjunto de reglas de arbitraje diferente de su propio reglamento para aplicar el Reglamento sobre la Transparencia. Esto podría ir en contra del objetivo de lograr la aplicación más amplia posible del Reglamento.

15. Si el Reglamento sobre la Transparencia fuese un reglamento independiente, podría aplicarse a cualquier otro reglamento de arbitraje, lo que daría lugar a una aplicación más amplia de este Reglamento. El Reglamento sobre la Transparencia podría aplicarse a otro reglamento de arbitraje, dado que las partes son libres de acordar la modificación de las reglas de arbitraje aplicables (véase también el documento A/CN.9/WG.II/WP.173). Las instituciones arbitrales han aplicado una norma de transparencia superior en las actuaciones arbitrales, cuando ese ha sido el deseo expresado por las partes (véase el documento A/CN.9/736, párr. 28). El Grupo de Trabajo puede tomar nota, si lo estima oportuno, de que en su 56º período de sesiones las instituciones arbitrales a que se refiere el documento A/CN.9/WG.II/WP.170 y Add.1 observaron que el Reglamento sobre la Transparencia en forma de texto independiente podría funcionar conjuntamente con sus respectivos reglamentos institucionales (A/CN.9/741, párr. 29; véase también el documento A/CN.9/WG.II/WP.173).

16. La presunción sobre la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia contenida en el artículo 1 1) del proyecto de dicho Reglamento se aplicaría en la misma medida, tanto si el Reglamento adoptase la forma de reglamento independiente o de apéndice.

b. Tratados ya existentes

17. En el 56º período de sesiones del Grupo de Trabajo, las delegaciones expresaron su preocupación acerca de la dificultad de excluir la posibilidad de una interpretación dinámica, como se pretendía hacer, si el Reglamento sobre la Transparencia se presentase como apéndice al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (A/CN.9/741, párr. 57). En sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo se refirió a la “interpretación dinámica”, cuando un tratado de inversiones permitiera la aplicación de la versión más reciente del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (A/CN.9/741, párr. 42). Si el Reglamento sobre la Transparencia se convirtiese en un apéndice del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 y, en consecuencia, ese Reglamento se actualizase y pasase a ser un conjunto de reglas específicas para el arbitraje en materia de inversiones (véase el párrafo 13), podría resultar particularmente difícil evitar su aplicación a los tratados existentes valiéndose del concepto de “la interpretación dinámica” y recurriendo a la versión más reciente del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Si el Reglamento sobre la Transparencia adoptase la forma de reglamento independiente, la posibilidad de una interpretación dinámica sería más limitada.

18. En cuanto a los distintos instrumentos que podría examinar el Grupo de Trabajo mediante los que el Reglamento sobre la Transparencia podría ser aplicable a los tratados de inversiones existentes, (A/CN.9/736, párrs. 134 a 135, y A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1, párrs. 10 a 23), la forma del Reglamento sobre la Transparencia, ya sea la de un instrumento independiente o la de un apéndice, no daría lugar a ninguna diferencia. Esos instrumentos incluirían: i) una recomendación por la que se inste a los Estados a que den aplicabilidad al reglamento en el contexto de la solución de controversias entre inversionistas y Estados regidas por un tratado; ii) una convención en virtud de la cual los Estados puedan consentir en la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia a arbitrajes regidos por sus tratados de inversiones existentes; y iii) declaraciones interpretativas conjuntas hechas de conformidad con el artículo 31, párrafo 3) a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (“la Convención de Viena”); o iv) una enmienda o modificación introducida en los tratados de inversiones existentes de conformidad con los artículos 39 a 41 de la Convención de Viena.

Párrafo 2) - Aplicación del Reglamento sobre la Transparencia por las partes litigantes

19. El artículo 1 2), tal como figura en el párrafo 6, refleja las modificaciones consideradas aceptables por el Grupo de Trabajo en su 56º período de sesiones (A/CN.9/741, párrs. 74, 78 y 81). El párrafo 2 del artículo 1 refleja el principio según el cual las partes litigantes no podrán retraerse del cumplimiento del Reglamento sobre la Transparencia, salvo que así lo establezca el tratado. La razón es que no sería apropiado que las partes litigantes revocaran una decisión adoptada al respecto por los Estados Partes en el tratado de inversiones y que el Reglamento sobre la Transparencia pretende beneficiar no solo al inversionista y al Estado anfitrión, sino también a la población en su conjunto (A/CN.9/741, párr. 61). De conformidad con la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo en su 56º período de sesiones, el artículo 1 2) prevé, además, la posibilidad de que el tribunal arbitral pueda adaptar el Reglamento sobre la Transparencia para asegurar la eficacia de las actuaciones arbitrales, sin permitir excepciones a éste (A/CN.9/741,

párrs. 73, 74, 78 y 81). El Grupo de Trabajo podrá considerar, además, la posibilidad de analizar las circunstancias que podrían dar lugar a dicha adaptación (A/CN.9/741, párr. 73). En lo que respecta a la redacción, cabe señalar a la atención del Grupo de Trabajo que si se mantuviera la referencia a las partes litigantes en el párrafo 1, se suprimiría en el artículo 1 2) a) la definición de partes litigantes.

Párrafo 3) - Relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el reglamento de arbitraje aplicable

20. En el 56° período de sesiones del Grupo de Trabajo, la gran mayoría de las delegaciones era partidaria de incluir en el Reglamento sobre la Transparencia una disposición sobre la relación entre ese Reglamento y el reglamento de arbitraje aplicable. Cabe señalar a la atención del Grupo de Trabajo que la referencia en la disposición actual relativa a la relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el reglamento de arbitraje aplicable contenida en el artículo 1 3), únicamente se hace con relación a las “normas de arbitraje aplicables”, dado que refleja la versión vigente del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y cualquier otro reglamento de arbitraje.

Párrafo 4) - Relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el derecho aplicable

21. En su 56° período de sesiones, el Grupo de Trabajo dio instrucciones a la secretaría para que complementase la disposición relativa a la relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el reglamento de arbitraje aplicable, mediante una disposición sobre la relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el derecho aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 3) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 (A/CN.9/741, párr. 97). El Grupo de Trabajo podrá examinar, si lo estima oportuno, el artículo 1 4) contenido en el párrafo 6 *supra*, que refleja rigurosamente el enunciado del artículo 1 3) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010. Cabe señalar a la atención del Grupo de Trabajo que, en función de la legislación interna aplicable con relación al derecho de los tratados y la transparencia, existe la posibilidad de que las Partes puedan retraerse del cumplimiento del Reglamento sobre la Transparencia.

Párrafo 5) - Discrecionalidad del tribunal arbitral

22. En su 56° período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del párrafo sobre la discrecionalidad del tribunal arbitral (A/CN.9/741, párr. 85), que prevé el ejercicio de la discrecionalidad del tribunal arbitral cuando así lo permita el Reglamento sobre la Transparencia, teniendo en cuenta la necesidad de equilibrar: a) el interés público en la transparencia de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado de inversiones y del proceso arbitral en particular, y b) el interés de las partes litigantes en que la controversia se resuelva de manera justa y eficaz.

Nota a pie de página del artículo 1 1)

23. El Grupo de Trabajo podrá examinar, si lo estima oportuno, la nota del artículo 1 1), que ofrece una definición de la expresión “un tratado que prevea la protección de las inversiones o de los inversionistas” en virtud del Reglamento

sobre la Transparencia, y refleja las propuestas de redacción formuladas en el 56º período de sesiones del Grupo de Trabajo. La nota tiene por objeto aclarar que la idea de que el Reglamento sobre la Transparencia sería aplicable a los tratados de inversiones debería interpretarse en sentido amplio (A/CN.9/741, párrs. 101 a 102). En dicho período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó la nota, sujeta a la supresión del término “intergubernamentales” después de las palabras “u organizaciones” y a que se aluda a la “protección de las inversiones y los inversionistas” de forma coherente.

Artículo 2. Publicación de información tras el inicio de las actuaciones arbitrales

24. Proyecto de artículo 2 - Publicación de información tras el inicio de las actuaciones arbitrales.

“Una vez que el demandado haya recibido la notificación del arbitraje, las partes litigantes comunicarán sin demora al archivo mencionado en el artículo 9 una copia de la notificación del arbitraje. Tras la recepción de la notificación de arbitraje de cualquiera de las partes, el archivo procederá sin demora a poner a disposición del público la información relativa al nombre de las partes litigantes, el sector económico afectado y el tratado en virtud del cual se formula la reclamación.”

Observaciones

25. En su 56º período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó la versión del proyecto de artículo 2 por la que la publicación de la notificación de arbitraje (y de su contestación) se regularía en virtud del artículo 3 una vez constituido el tribunal arbitral, con algunos cambios de redacción (A/CN.9/741, párr. 109).

26. El proyecto de artículo 2 contiene las modificaciones de redacción acordadas por el Grupo de Trabajo (A/CN.9/741, párr. 109), con el fin de aclarar que todas las partes litigantes estarán obligadas a enviar la notificación de arbitraje al archivo. El archivo a su vez, deberá publicar la información una vez que reciba la notificación de arbitraje de cualquiera de las Partes.

27. El Grupo de Trabajo podrá examinar, si lo estima oportuno, cómo tratar las situaciones en que el demandante envíe la notificación de arbitraje al archivo antes de que comiencen las actuaciones arbitrales, es decir, antes de que el demandado haya recibido dicha notificación (A/CN.9/741, párr. 107). El Grupo de Trabajo también podrá determinar si las palabras iniciales “una vez que el demandado haya recibido la notificación del arbitraje” resuelven satisfactoriamente la cuestión. Además, el Grupo de Trabajo podrá examinar las dificultades que esa situación puede suponer para el archivo en lo que respecta al cumplimiento de sus funciones administrativas.

28. En su 56º período de sesiones, el Grupo de Trabajo propuso armonizar los términos empleados en el Reglamento respecto de la publicación de información o de documentos, pues, por ejemplo, unas veces se habla de “publicar” y otras de “poner a disposición del público”. El Grupo de Trabajo pidió a la secretaría que examinase si se había querido dar un significado distinto a los diversos términos empleados respecto de la publicación y que estudiase la forma de lograr un enfoque uniforme. Cabe señalar a la atención del Grupo de Trabajo que la palabra “publicar”

únicamente aparece en el actual proyecto de Reglamento sobre la Transparencia en el título del proyecto de artículo 9, a saber, “Archivo de la información publicada” (proyectos de artículos 1 y 2, contenidos en el documento A/CN.9/WG.II/WP.172, y proyectos de artículos 3 a 9, contenidos en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169 y Add.1). En el proyecto de reglamento se utiliza el sustantivo “publicación” y el verbo “poner a disposición del público” con el mismo significado.

**C. Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales:
preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los
arbitrajes entablados entre inversionistas y Estados en el marco de
un tratado — Observaciones presentadas por instituciones arbitrales
acerca de las relaciones entre el proyecto de reglamento sobre la
transparencia y sus respectivas reglas institucionales, presentada
al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en
su 57º período de sesiones
(A/CN.9/WG.II/WP.173)**

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1
II. Observaciones recibidas de instituciones arbitrales	
A. Corte Permanente de Arbitraje (CPA)	
B. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)	
C. Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA)	
D. Centro Regional de Arbitraje Mercantil Internacional de El Cairo	
E. Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo	

I. Introducción

1. Las instituciones arbitrales que habían manifestado su interés por asociarse a la labor actual del Grupo de Trabajo relativa a la preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado han presentado observaciones sobre cuestiones que pudieran plantearse en la aplicación del reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia, que se está preparando, a los casos de arbitraje que se administraran en virtud de sus respectivos reglamentos de arbitraje (A/CN.9/736, en el párrafo 28). Las observaciones recibidas de las instituciones arbitrales se reproducen a continuación (véase también A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1, párr. 35).

II. Observaciones recibidas de instituciones arbitrales

A. Corte Permanente de Arbitraje (CPA)

Respuesta del Secretario General Adjunto,

Fecha: 11 de enero de 2012

Actualmente, las partes pueden elegir entre los siguientes reglamentos de arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA): el Reglamento Optativo de la CPA para el arbitraje de controversias entre dos Estados; el Reglamento Optativo de la CPA para el arbitraje de controversias entre dos partes, de las cuales una sea un Estado; el Reglamento Optativo de la CPA para el arbitraje de controversias entre organizaciones internacionales y Estados; el Reglamento Optativo de la CPA para el arbitraje de controversias entre organizaciones internacionales y entidades privadas o personas; el Reglamento Optativo de la CPA para el arbitraje de controversias relativas a recursos naturales y al medio ambiente; y el Reglamento Optativo de la CPA para el arbitraje de controversias relativas a actividades en el espacio ultraterrestre.

A primera vista, cabe indicar que los Reglamentos mencionados de la CPA, que se basan en la versión de 1976 o en la versión de 2010 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, pueden aplicarse paralelamente y sin conflicto con el reglamento sobre la transparencia, tal como figura actualmente redactado¹. La CPA se reserva el derecho a modificar o complementar su respuesta si en el futuro se producen modificaciones en el proyecto de reglamento sobre la transparencia.

B. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)

Respuesta del Secretario General

Fecha: 18 de enero de 2012

1. En el presente documento, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) presenta observaciones sobre la posible interacción entre el Reglamento de Arbitraje del CIADI y el proyecto de reglamento sobre la transparencia que actualmente figura en los documentos A/CN.9/WG.II/WP.169 y A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1.

2. El CIADI administra procedimientos de arbitraje regidos por el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI respecto de casos especiales, como en el contexto del TLCAN y de diversos tratados bilaterales de inversiones. Las observaciones que formuló la secretaría de la CNUDMI en los párrafos 13 a 34 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1 serían aplicables a los casos de la CNUDMI administrados por el CIADI. Así pues, cualquier disposición sobre la transparencia

¹ Anteriormente, las partes en arbitrajes regidos por Reglamentos de la CPA convinieron en requisitos muy amplios para la divulgación. Por ejemplo, en el arbitraje *Abyei* (caso de la CPA núm. 2008-5), que se rigió por el Reglamento Optativo de la CPA para arbitrajes de controversias entre dos partes, de las cuales una sea un Estado, las partes convinieron en hacer públicas las actuaciones orales y escritas, así como el laudo final.

adoptada por la Comisión podría aplicarse a los casos de la CNUDMI administrados por el CIADI.

3. En virtud del Convenio del CIADI, el Centro presta servicios de conciliación y arbitraje de diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes. El Consejo Administrativo del Centro ha adoptado también el Reglamento del Mecanismo Complementario por el que se autoriza al Secretariado del Centro a administrar procedimientos que no entran en el ámbito de aplicación del Convenio del CIADI, como sucede si una de las partes no es un Estado Contratante o un nacional de un Estado Contratante (por ejemplo, el Canadá o México) o si en los procedimientos por lo menos una de las partes es un Estado Contratante o un nacional de un Estado Contratante, para el arreglo de diferencias que no surjan directamente de una inversiones, a condición de que la operación básica se distinga de una operación comercial ordinaria.

4. En la interacción entre el proyecto de reglamento de transparencia de la CNUDMI y el Convenio del CIADI y el Reglamento de Arbitraje del Centro se asumiría que el reglamento de la CNUDMI podría aplicarse a un procedimiento de arbitraje del CIADI. Sobre la base de las deliberaciones mantenidas hasta la fecha por el Grupo de Trabajo y habida cuenta de los debates que aún deben celebrarse acerca del ámbito de aplicación del reglamento, el Centro no está actualmente en condiciones de formular más observaciones.

C. Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA)

Respuesta del Director General

Fecha: 20 de enero de 2012

Introducción

Se ha pedido a la LCIA que formulara observaciones sobre las relaciones entre el reglamento, la práctica y el procedimiento de la Corte y el proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, en caso de que ambos debieran aplicarse conjuntamente.

Las observaciones presentadas se refieren únicamente a cuestiones prácticas dimanantes de la función de la LCIA como administradora o como “archivo” designado, y no guardan relación con las funciones, los derechos y las responsabilidades de las partes y del tribunal.

Las referencias a “la LCIA” pueden guardar relación con la secretaría de la LCIA o con la Corte en sí. No obstante, la Corte es la autoridad final para la aplicación del reglamento, la práctica y el procedimiento adoptado por la LCIA para la administración de arbitrajes, ya sea aplicados por la secretaría en nombre de la Corte, o por la Corte propiamente dicha, en la persona de su Presidente, sus Vicepresidentes o sus Divisiones.

Reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia

Proyecto de artículo 1. Ámbito de aplicación

Párrafo 1: En su redacción actual, la opción 2, variante 1 [del párrafo 1 del artículo 1 que figura en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169, párr. 8] es la única versión mediante la cual el reglamento sobre la transparencia podría ser aplicable a procedimientos de arbitraje regidos por reglamentos distintos del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

Párrafo 2: Se toma nota del carácter imperativo del reglamento sobre la transparencia.

Párrafos 3 a 5: Se toma nota de la prioridad que tendría el reglamento sobre la transparencia en relación con los reglamentos de arbitraje aplicables, si hubiera conflicto. La LCIA se adhiere al CIADI, a la CPA, a la Cámara de Comercio de Estocolmo y a la Cámara de Comercio Internacional confirmando el principio de que es improbable que la aplicación del reglamento sobre la transparencia paralelamente al reglamento de arbitraje de la LCIA cause problemas.

No obstante, la posición de la Corte puede variar a medida que se modifique la redacción del proyecto de reglamento sobre la transparencia.

Proyecto de artículo 2. Publicación de información tras el inicio de las actuaciones arbitrales

En virtud del artículo 30.1 del reglamento de arbitraje de la LCIA, las partes, salvo que acuerden por escrito lo contrario, se comprometen a mantener, como principio general, la confidencialidad de todo el material del procedimiento creado y producido para los fines del arbitraje. Con la adopción por las partes, por escrito, del reglamento sobre la transparencia, quedaría convenido que ese material no habría de mantenerse confidencial.

Cuando se requiriera a la LCIA que actuara como archivo para los fines del reglamento sobre la transparencia, crearía un sitio especial con el pertinente servidor, que utilizaría y mantendría al margen de su propio sitio, a fin de garantizar una mayor eficiencia y de facilitar el funcionamiento y el acceso, salvaguardando así la confidencialidad de otros arbitrajes pendientes ante la LCIA a los que fueran aplicables las disposiciones sobre confidencialidad del artículo 30 del reglamento de arbitraje de la Corte.

Proyecto de artículo 3. Publicación de documentos

Véanse las observaciones que figuran más arriba en relación con el artículo 2.

Se toma nota de las excepciones a la publicación enunciadas en el artículo 8, ya que corresponde al tribunal, en virtud del artículo 3.4, asegurar que los documentos que no deban divulgarse se mantengan al margen del archivo o sean debidamente expurgados.

En caso de que una institución arbitral actuara no solamente como archivo, sino que también se ocupara de la administración en virtud de su propio reglamento conjuntamente con el reglamento sobre la transparencia, la propia institución recibiría presumiblemente los documentos que no habrían de divulgarse. En ese

caso, la institución esperaría que la Corte le notificara los documentos que deberían excluirse del archivo público o que deberían expurgarse.

Proyecto de artículo 4. Publicación de los laudos arbitrales

Como en el caso anterior, la adopción del reglamento sobre la transparencia equivaldría a un acuerdo por escrito de que el laudo no debería mantenerse confidencial, para los fines del artículo 30.1 del reglamento de arbitraje de la LCIA.

También conforme a lo anterior, si la institución administrara el arbitraje en virtud de su propio reglamento, y no actuara simplemente como archivo, conocería los laudos no expurgados, si bien, en su caso, sólo se divulgarían las versiones expurgadas.

Tomamos nota de la utilización, en los artículos 2, 3 y 4, de los términos “*sin demora*” y “*oportunamente*” en relación con la obligación del archivo de divulgar los materiales. Sería útil que se dieran orientaciones sobre la forma en que deben interpretarse esas palabras.

Proyecto de artículo 5. Presentaciones a cargo de terceros

El hecho de que en el reglamento de la LCIA no exista ninguna disposición para la intervención de *amici curiae* no prohíbe que las partes convengan expresamente en que se permita tal intervención de acuerdo con los procedimientos establecidos en el presente artículo.

Proyecto de artículo 6. Presentaciones de una parte en el tratado que no sea litigante

Tomamos nota de que el Grupo de Trabajo aún no ha determinado si el tribunal debe tener discreción para aceptar o rechazar las presentaciones hechas por partes en el tratado que no sean litigantes. Tomamos nota también de que aún queda por debatir si una parte no litigante debe estar facultada para hacer presentaciones no sólo sobre cuestiones de interpretación de los tratados sino también sobre cuestiones de hecho o de derecho o sobre cuestiones que entren en el ámbito de la controversia. No obstante, parece evidente que estas cuestiones afectan a las partes y al tribunal, pero no a la institución administradora o al archivo.

Tomamos nota, sin embargo, de que los documentos presentados de conformidad con los artículos 5 y 6 del reglamento sobre la transparencia deben hacerse públicos en virtud del artículo 3.

Proyecto de artículo 7. Audiencias

El artículo 19.4 del reglamento de arbitraje de la LCIA dispone que todas las sesiones y audiencias se celebrarán a puerta cerrada, a menos que las partes convengan por escrito en lo contrario o que el tribunal arbitral decida otra cosa. La adopción del reglamento sobre la transparencia equivaldría a un acuerdo por escrito en el sentido de que las audiencias no deben ser privadas.

En otro orden de cosas, en relación con el artículo 7.3, la secretaría de la Corte estaría a la disposición del tribunal para encargarse de cualquier arreglo logístico mencionado en el artículo, en caso de que el arbitraje se rigiera por el reglamento de la LCIA.

Proyecto de artículo 8. Excepciones a la norma de la transparencia

Corresponde al tribunal y a las partes decidir qué información no deberá divulgarse o comunicarse a las partes no litigantes. Sin embargo, es esencial que los mecanismos, cuya finalidad es asegurar que el administrador o el archivo no divulgue esos materiales, sean eficaces, teniendo presente la obligación del archivo de proceder a la publicación “*sin demora*” u “*oportunamente*”.

D. Centro Regional de Arbitraje Mercantil Internacional de El Cairo

Respuesta del Director
Fecha: 20 de enero de 2012

I. Observaciones generales

Desde que fue establecido, el Centro Regional de El Cairo adoptó, con ligeras modificaciones, el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976 (“el Reglamento de la CNUDMI”). El Centro modificó su propio reglamento de arbitraje en 1998, 2000, 2002 y 2007, a fin de asegurar que siguiera satisfaciendo las necesidades de sus usuarios y reflejando las mejores prácticas en materia de arbitraje institucional internacional.

El actual Reglamento de Arbitraje del Centro (“el Reglamento”) entró en vigor en marzo de 2011. Se basa en el nuevo Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, revisado en 2010, con ligeras modificaciones dimanantes principalmente de la función que tiene el Centro como institución arbitral y autoridad nominadora.

El Reglamento es igualmente aplicable a procedimientos de arbitraje comercial y sobre inversiones.

El artículo 40 del Reglamento prevé la confidencialidad como principio general; no obstante, las partes pueden convenir en no aplicar ese principio.

II. El Tratado y el Reglamento de la CNUDMI frente al Reglamento

En esta sección, comentaremos la interacción entre el Tratado y el Reglamento de la CNUDMI que se reseña en los párrafos 13 a 34 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1 de la CNUDMI, que también son aplicables para el Reglamento. Para facilitar la consulta, seguiremos las disposiciones en el mismo orden.

a. Modificación**Publicación de laudos arbitrales**

A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1: párrafo 16.

Artículo pertinente del Reglamento de Arbitraje del Centro de El Cairo: artículo 40, párrafos 1 y 3.

¿Las mismas consecuencias para el Reglamento que para el Reglamento de la CNUDMI? Sí.

Observaciones: la confidencialidad es regulada por el artículo 40, cuya aplicación las partes pueden excluir.

Audiencias

Texto del documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1: párrafo 17.

Artículo pertinente del Reglamento de Arbitraje del Centro: artículo 28, párrafo 3.

¿Las mismas consecuencias para el Reglamento que para el Reglamento de la CNUDMI? Sí.

Observaciones: en el Reglamento figura el mismo párrafo.

b. Disposiciones complementarias

Ámbito de aplicación - artículo 1 del reglamento sobre la transparencia

Texto del documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1: párrafos 19 a 23.

Artículo pertinente del Reglamento de Arbitraje del Centro: artículo 1, párrafo 2.

Observaciones: el párrafo 2 del artículo 1 del Reglamento dispone que la versión aplicable del reglamento será la que esté en vigor en la fecha de inicio del procedimiento arbitral, a menos que se convenga otra cosa.

Por consiguiente, el Reglamento será aplicable a las controversias iniciadas después de marzo de 2011, aun cuando el tratado de inversiones se hubiera firmado antes de esa fecha. No obstante, esto es solamente pertinente cuando la versión final del Tratado incluya la variante que prevea su aplicabilidad con reglamentos distintos del Reglamento de la CNUDMI.

Artículo 1, párrafo 3, del reglamento sobre la transparencia

Texto del documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1: párrafo 24.

Artículo pertinente del Reglamento de Arbitraje del Centro: artículo 17, párrafo 1.

¿Las mismas consecuencias para el Reglamento que para el Reglamento de la CNUDMI? Sí.

Observaciones: en el Reglamento figura el mismo párrafo y, por lo tanto, el mismo efecto es aplicable al Reglamento de la CNUDMI.

Inicio del procedimiento arbitral - artículo 2 del reglamento sobre la transparencia

Texto del documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1: párrafo 25.

Artículo pertinente del Reglamento de Arbitraje del Centro: artículo 4.

Observaciones: el artículo 4 dispone que deberán presentarse al Centro todos los documentos para el caso en que el Centro actúe como archivo y/o se facilitarán al Centro copias para enviar al archivo pertinente, de estar obligado a ello.

Publicación de documentos - artículo 3 del reglamento sobre la transparencia

Texto del documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1: párrafo 26.

Observación: dado que el instituto arbitral administra el caso, deberán comunicársele todos los documentos por conducto del Centro.

Presentaciones a cargo de terceros - artículo 5 del reglamento sobre la transparencia

Presentación por una parte en el tratado que no sea litigante - artículo 6 del reglamento sobre la transparencia

Texto del documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1: párrafos 27 y 28.

¿Las mismas consecuencias para el Reglamento que para el Reglamento de la CNUDMI? Sí.

Observaciones: el Centro tampoco dice nada respecto de las presentaciones por partes que no sean litigantes. Por consiguiente, habrá un mismo efecto para el Reglamento de la CNUDMI.

c. Sin efecto

Excepciones a la norma de la transparencia - artículo 8 del reglamento sobre la transparencia

Texto del documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1: párrafos 29 y 30.

Artículo pertinente del Reglamento de Arbitraje del Centro: artículo 40.

¿Las mismas consecuencias para el Reglamento que para el Reglamento de la CNUDMI? No.

Observaciones: una vez más, el artículo 40, que regula la confidencialidad, dispone que la totalidad del proceso será confidencial, a menos que las partes convengan otra cosa. Por consiguiente, el artículo 8 del Tratado tendrá un efecto “modificador” en el Reglamento, a diferencia de lo que ocurrirá con el Reglamento de la CNUDMI.

Archivo de la información y puesta a disposición del público - artículo 9 del reglamento sobre la transparencia y nombramiento de autoridades

Texto del documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1: párrafos 31 a 33.

Observaciones: estas funciones ya son ejercidas por el Centro como institución arbitral, con excepción de la publicación de documentos. Si el archivo fuera una dependencia distinta del Centro, los artículos que prevén que el Centro tendrá una función nominadora serían por tanto modificados.

Asignación de costas

Texto del documento A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1: párrafo 34.

Artículo pertinente del Reglamento de Arbitraje del Centro: artículo 46.

¿Los mismos efectos para el Reglamento que para el Reglamento de la CNUDMI? Sí.

Observaciones: si bien el Reglamento difiere del Reglamento de la CNUDMI en su regulación de las costas de arbitraje, ambos reglamentos asignan en principio las costas a la parte perdedora. La sección V del Reglamento regula las costas del arbitraje.

III. El Tratado y el Reglamento: posibilidades que no existen con el Reglamento de la CNUDMI

Como ya se ha indicado, el Reglamento contiene un artículo que regula la confidencialidad y que no existe en el Reglamento de la CNUDMI. No obstante, las partes en el arbitraje pueden convenir en apartarse de esa disposición. En consecuencia, el Tratado tendrá un efecto modificador en el Reglamento a este respecto.

Dado que, a diferencia del Reglamento de la CNUDMI, el Reglamento del Centro es aplicable a instituciones arbitrales, en él se refleja la función del Centro. Según las funciones que tenga el archivo, el Centro le puede resultar útil en caso de que el Tratado prevea disposiciones relativas a la interacción entre la función de la institución que administra el procedimiento y el archivo.

E. Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo

Respuesta del Secretario General

Fecha: 23 de enero de 2012

Hemos recibido el informe del Grupo de Trabajo sobre Arbitraje acerca de la labor realizada en su 55º período de sesiones (A/CN.9/736), el proyecto de reglamento sobre la transparencia (A/CN.9/WG.II/WP.169), las observaciones sobre las relaciones entre el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y el proyecto de reglamento sobre la transparencia (A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1, párrs. 13 a 34) y la pregunta formulada en su carta del 14 de diciembre de 2011.

A continuación figura una evaluación preliminar de la posible interacción entre el Reglamento de la Cámara de Comercio de Estocolmo (CCE) y el proyecto de reglamento sobre la transparencia.

A modo de resumen cabe decir que la CCE no prevé que el proyecto de reglamento sobre la transparencia cree problemas para los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado que se rijan por el Reglamento de la CCE cuando se aplique el proyecto de reglamento sobre la transparencia.

En aras de la claridad, la CCE desearía subrayar que no debería interpretarse nada de lo que figura a continuación en el sentido de que la CCE propugna una determinada norma sobre la transparencia. El objetivo ha consistido en señalar el modo en que el Reglamento de la CCE funcionaría paralelamente al proyecto de reglamento sobre la transparencia. La CCE es consciente de que el reglamento sobre la transparencia aún no se ha finalizado, por lo que esta respuesta se presenta con la reserva de que, cuando se adopte la versión final del texto, tal vez deba hacerse un análisis diferente.

En este documento se reseña la posible interacción entre el Reglamento de la CCE y el proyecto de reglamento sobre la transparencia en el contexto de un arbitraje entablado entre inversionistas y Estados sobre la base de un tratado. El Reglamento de la CCE es aplicable tanto en los procedimientos arbitrales comerciales como en los entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado.

En primer lugar, se formulan algunas observaciones generales sobre la interacción entre el Reglamento de la CCE y el proyecto de reglamento sobre la transparencia. A continuación las observaciones siguen el formato de la nota de la Secretaría relativa a las relaciones entre el proyecto de reglamento sobre la transparencia y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1, párrs. 13 a 34) con observaciones concretas sobre el modo en que las disposiciones del proyecto de reglamento modificarían o complementarían el Reglamento de la CCE o no repercutirían en él.

EL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESTOCOLMO (CCE) Y EL PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE LA TRANSPARENCIA

El reglamento sobre la transparencia puede ser aplicable en función de las distintas opciones descritas en el artículo 1 (Ámbito de aplicación). Los arbitrajes que se rijan a la vez por el Reglamento de la CCE y por el proyecto de reglamento sobre la transparencia solamente pueden producirse en virtud de la opción 2, variante 1, del artículo 1.1 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, por la obvia

razón de que la opción 1 y la opción 2, variante 2, se refieren a los arbitrajes regidos por el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. A fin de que el reglamento sobre la transparencia sea aplicable a los arbitrajes regidos por el Reglamento de la CCE, es preciso que en el acuerdo de arbitraje de la controversia entre inversionistas y Estados sobre la base de un tratado: i) se haga remisión al Reglamento de la CCE; y ii) se incorpore el reglamento sobre la transparencia.

El Reglamento de la CCE consta de muchas disposiciones que pueden modificarse mediante acuerdo entre las partes. El párrafo 1) del artículo 19 del Reglamento de la CCE dispone que “sujeto a este Reglamento y a cualquier acuerdo entre las partes, el Tribunal Arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado”. Por consiguiente, no es probable que la aplicación del proyecto de reglamento sobre la transparencia entre en conflicto con el Reglamento de la CCE si el reglamento sobre la transparencia, en virtud de la opción 2, variante 1 del artículo 1.1, forma parte del acuerdo de arbitraje suscrito por las partes.

En el informe del Grupo de Trabajo sobre Arbitraje acerca de la labor realizada en su 55º período de sesiones (A/CN.9/736), la Secretaría señaló que el Grupo de Trabajo convino en enmendar el texto del proyecto de reglamento sobre la transparencia de modo que la terminología empleada se ajustara a la del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 (véanse, por ejemplo, los párrafos 15, 39 y 61). En algunos casos, la terminología utilizada en el proyecto de reglamento sobre la transparencia difiere de la empleada en el Reglamento de la CCE. Por ejemplo, en el artículo 2 del proyecto de reglamento sobre la transparencia se hace referencia a la “notificación de arbitraje”, mientras que en el artículo 2 del Reglamento de la CCE ese documento se denomina “solicitud de arbitraje”. Como observación general acerca de la distinta terminología, la CCE no prevé que esas diferencias terminológicas influyan en la interacción entre el proyecto de reglamento sobre la transparencia y el Reglamento de la CCE.

Si bien es improbable que la distinta terminología afecte a la interacción entre ambos reglamentos, la CCE desearía subrayar que su Reglamento y el proyecto de reglamento sobre la transparencia difieren en lo relativo al momento en que se da por iniciado un procedimiento de arbitraje. En virtud del artículo 4 del Reglamento de la CCE, el inicio del arbitraje se producirá en la fecha en que la CCE reciba la solicitud de arbitraje. En el artículo 2 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, que se titula “Publicación de información tras el inicio de las actuaciones arbitrales”, no se hace referencia a que el papel de la institución, tanto en la opción 1 como en la opción 2, sea importante para determinar la fecha de “inicio de las actuaciones arbitrales”. La Cámara de Comercio de Estocolmo considera más bien que, según el artículo 2 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, el arbitraje se inicia “una vez que el demandado haya recibido la notificación del arbitraje”, de modo similar a lo dispuesto en el artículo 3.2 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010. Si bien se desconoce por el momento el efecto que puede tener esa diferencia, la CCE desea ponerla de relieve.

A modo de conclusión y como observación general, la CCE indica que varias disposiciones del proyecto de reglamento sobre la transparencia requieren del tribunal arbitral que ejerza su discreción al aplicar ese reglamento (véanse, por ejemplo, el artículo 5 sobre la autorización de presentaciones a cargo de terceros, y el artículo 8.7 sobre las excepciones a la norma de la transparencia). En caso de que el tribunal arbitral no pudiera llegar a una decisión unánime sobre esas

cuestiones discrecionales, la cuestión se resolverá aplicando el artículo 35 del Reglamento de la CCE. Este artículo dispone que cuando el tribunal arbitral esté integrado por más de un árbitro, las decisiones deberán adoptarse por mayoría de árbitros o, de no alcanzarse la mayoría, por el Presidente. El tribunal arbitral podrá decidir asimismo que su presidente esté facultado para tomar por sí mismo resoluciones procesales.

Siguiendo el formato de la nota de la Secretaría sobre las relaciones entre el reglamento sobre la transparencia y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (A/CN.9/WG.II/WP.169/Add.1, párrs. 13 a 34), las observaciones de la CCE sobre la interacción concreta entre las disposiciones del Reglamento de la CCE y el proyecto de reglamento sobre la transparencia se dividen en tres aspectos: a) las disposiciones del proyecto de reglamento sobre la transparencia que modificarían el Reglamento de la CCE; b) las disposiciones del proyecto de reglamento sobre la transparencia que complementarían el Reglamento de la CCE; y c) las disposiciones del proyecto de reglamento sobre la transparencia que no repercutirían en el Reglamento de la CCE.

a. Modificaciones de las disposiciones del Reglamento de la CCE

Los artículos 3, 4, 7 y 9 (opción 2, párrafo 1) del proyecto de reglamento sobre la transparencia constituirían acuerdos entre las partes que modificarían las disposiciones supletorias del Reglamento de la CCE.

Publicación de documentos - Artículo 3 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, que modifica el artículo 46 del Reglamento de la CCE

En virtud del artículo 3 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, el tribunal arbitral debe comunicar al archivo los documentos para su publicación. El artículo 46 del Reglamento de la CCE requiere que el tribunal arbitral mantenga la confidencialidad del arbitraje. La disposición sobre confidencialidad del Reglamento de la CCE está sujeta a que las partes convengan lo contrario, y la adopción del proyecto de reglamento sobre la transparencia constituiría un acuerdo de las partes para modificar las disposiciones del Reglamento de la CCE.

Publicación de los laudos arbitrales - Artículo 4 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, que modifica el artículo 46 del Reglamento de la CCE

El artículo 4 del proyecto de reglamento sobre la transparencia requiere del tribunal arbitral que comunique el laudo arbitral al archivo. El artículo 46 del Reglamento de la CCE exige del tribunal arbitral que mantenga la confidencialidad del laudo. La disposición sobre confidencialidad del Reglamento de la CCE está sujeta a lo que acuerden las partes, y la adopción del proyecto de reglamento sobre la transparencia constituiría un acuerdo entre las partes que modificaría las disposiciones del Reglamento de la CCE.

Audiencias - Artículo 7 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, que modifica el artículo 27 3) del Reglamento de la CCE

El artículo 7.1 del proyecto de reglamento sobre la transparencia requiere que las audiencias sean públicas, a menos que el tribunal decida otra cosa tras celebrar consultas con las partes litigantes. El párrafo 3) del artículo 27 del Reglamento de

la CCE dispone que, salvo acuerdo en contrario de las partes, las audiencias se celebrarán en privado. La adopción del proyecto de reglamento sobre la transparencia constituiría un acuerdo entre las partes de modificación de las disposiciones supletorias del Reglamento de la CCE, requiriéndose que las audiencias sean públicas.

Archivo de la información puesta a disposición del público - Artículo 9 (opción 2, párrafo 1) del proyecto de reglamento sobre la transparencia, que modifica el artículo 46 del Reglamento de la CCE

El artículo 9 (opción 2, párrafo 1) del proyecto de reglamento sobre la transparencia requiere que la institución arbitral que administre el procedimiento arbitral se encargue de poner la información a disposición del público conforme al reglamento. El artículo 46 del Reglamento de la CCE requiere que la Cámara de Comercio de Estocolmo mantenga la confidencialidad del arbitraje y del laudo y esta disposición está expresamente sujeta a la reserva de que las partes pueden acordar lo contrario. La adopción del proyecto de reglamento sobre la transparencia constituiría un acuerdo entre las partes que modificaría las disposiciones supletorias del Reglamento de la CCE, requiriéndose a la CCE que publique determinada información durante todo el arbitraje.

Esta explicación se ofrece con la reserva de que la Cámara de Comercio de Estocolmo vacilaría a la hora de revelar información en situaciones en que una de las partes estuviera en contra de la aplicación del reglamento sobre la transparencia antes de que se constituya el tribunal arbitral.

b. Complemento del Reglamento de la CCE

Los artículos 1 a 8 del proyecto de reglamento sobre la transparencia complementarían las disposiciones del Reglamento de la CCE.

Ámbito de aplicación - Artículo 1

El artículo 1, párrafo 1 (opción 2, variante 1), y párrafos 2, 4 y 5, del proyecto de reglamento sobre la transparencia, como complemento del Reglamento de la CCE en general en el marco del artículo 19, párrafo 1), del Reglamento de la CCE

En virtud del párrafo 1) del artículo 19 del Reglamento de la CCE, el arbitraje se sustanciará de conformidad con el acuerdo celebrado entre las partes. El artículo 1.1 (opción 2, variante 1) del proyecto de reglamento sobre la transparencia dispone que el reglamento será aplicado cuando lo disponga expresamente el tratado pertinente, y que el proyecto de reglamento sobre la transparencia formaría parte del acuerdo celebrado entre las partes por el que se dieran instrucciones al tribunal arbitral sobre cómo debería llevar el procedimiento. Por lo tanto, el proyecto de reglamento sobre la transparencia complementaría el Reglamento de la CCE.

El artículo 1, párrafo 3, del proyecto de reglamento sobre la transparencia, como complemento del artículo 19 del Reglamento de la CCE

El párrafo 3 del artículo 1 del proyecto de reglamento sobre la transparencia exige al tribunal arbitral que equilibre, por una parte, el interés público en la transparencia de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado y del proceso arbitral en particular, y, por otra, el interés de las partes litigantes en

que la controversia se resuelva de manera justa y eficaz. El artículo 19 del Reglamento de la CCE exige del tribunal arbitral que ejerza su discreción del modo que considere “apropiado” y velando por un arbitraje imparcial, práctico y expedito. Al requerir que el tribunal arbitral tenga en cuenta el interés público en la transparencia al ejercer su discreción, el proyecto de reglamento sobre la transparencia complementaría el Reglamento de la CCE.

Publicación de información tras el inicio de las actuaciones arbitrales - Artículo 2 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, como complemento de los artículos 2 y 5 del Reglamento de la CCE

El artículo 2 del proyecto de reglamento sobre la transparencia obliga a las partes litigantes a proporcionar información al archivo una vez recibida la notificación de arbitraje. Esta obligación complementa las obligaciones impuestas por los artículos 2 y 5 del Reglamento de la CCE a las partes litigantes al iniciar el procedimiento arbitral.

Publicación de documentos - Artículo 3 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, como complemento de los artículos 18 a 34 (“El procedimiento ante el Tribunal Arbitral”) del Reglamento de la CCE

El artículo 3 del proyecto de reglamento sobre la transparencia requiere al tribunal arbitral que comunique documentos al archivo para su publicación. Esta obligación no figura en los artículos 18 a 34 (capítulo titulado “El procedimiento ante el Tribunal Arbitral”) del Reglamento de la CCE. Por lo tanto, el artículo 3 del proyecto de reglamento sobre la transparencia complementaría esta disposición del Reglamento de la CCE.

Publicación de los laudos arbitrales - Artículo 4 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, como complemento del artículo 36, párrafo 4), del Reglamento de la CCE

El artículo 4 del proyecto de reglamento sobre la transparencia requiere que el tribunal arbitral comunique el laudo arbitral al archivo. En el párrafo 4) de su artículo 36, el Reglamento de la CCE obliga al tribunal arbitral a comunicar el laudo a cada una de las partes y a la CCE. En caso de que la Cámara de Comercio de Estocolmo actuara a la vez como institución administradora y como archivo (como en el artículo 9 (opción 2, párrafo 1) del proyecto de reglamento sobre la transparencia), el artículo 4 del proyecto de reglamento sobre la transparencia no tendría ninguna repercusión en los requisitos de comunicación del Reglamento de la CCE, dado que la CCE ya estaría en posesión del laudo. Sin embargo, en todos los otros casos, el artículo 4 del proyecto de reglamento sobre la transparencia complementaría los requisitos de comunicación del párrafo 4) del artículo 36 del Reglamento de la CCE al requerir que el tribunal arbitral comunique el laudo a un órgano adicional.

Presentaciones a cargo de terceros - Artículo 5 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, como complemento de los artículos 24 y 26 del Reglamento de la CCE

El artículo 5 del proyecto de reglamento sobre la transparencia permite al tribunal arbitral aceptar presentaciones de terceros, previa consulta con las partes litigantes. El Reglamento de la CCE no dice nada sobre las presentaciones a cargo de terceros.

El Reglamento de la CCE, en su artículo 24 sobre las presentaciones escritas y en su artículo 26 sobre la prueba, habla colectivamente de las partes, consistentes en el demandante y el demandado, pero no prevé expresamente presentaciones a cargo de terceros.

Actualmente no se tiene constancia de ningún arbitraje, basado en un tratado, entre inversionistas y Estados, o de otro tipo, regido por el Reglamento de la CCE en que haya habido presentaciones o intentos de presentaciones a cargo de terceros ante un tribunal arbitral.

El Reglamento de la CCE no limita las presentaciones a cargo de terceros. En virtud del párrafo 1) de su artículo 19, el tribunal arbitral goza de amplia discreción “para dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado”. El artículo 5 del proyecto de reglamento sobre la transparencia complementaría el Reglamento de la CCE.

Presentaciones de una parte en el tratado que no sea litigante - Artículo 6 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, como complemento de los artículos 24 y 26 del Reglamento de la CCE

El artículo 6 del proyecto de reglamento sobre la transparencia requiere o permite al tribunal arbitral invitar a partes en el tratado que no sean litigantes, previa consulta con las partes litigantes, a hacer presentaciones sobre la interpretación del tratado y sobre cuestiones de hecho y de derecho. El Reglamento de la CCE tampoco dice nada sobre las presentaciones de partes en el tratado que no sean litigantes y hasta la fecha no se tiene constancia de ningún arbitraje entre inversionistas y Estados, basado en un tratado y administrado por la CCE, en que una parte en el tratado que no sea litigante haya hecho o haya intentado hacer una presentación ante el tribunal arbitral.

En virtud del párrafo 1) del artículo 19 del Reglamento de la CCE, el tribunal arbitral goza de amplia discreción “para dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado”. El artículo 6 del proyecto de reglamento sobre la transparencia complementaría el Reglamento de la CCE.

Excepciones a la norma de la transparencia - Artículo 8 del proyecto de reglamento sobre la transparencia

El artículo 8 del proyecto de reglamento sobre la transparencia prevé excepciones a los requisitos de transparencia y define los conceptos de información confidencial, delicada y protegida y de medidas de protección de la integridad del proceso arbitral. El Reglamento de la CCE no contiene disposiciones análogas. Por lo tanto, el artículo 8 del proyecto de reglamento sobre la transparencia, que se aplica únicamente a la ejecución de ese reglamento, complementaría el Reglamento de la CCE.

c. Sin repercusiones para el Reglamento de la CCE

La CCE no prevé que el proyecto de reglamento sobre la transparencia vaya a afectar al marco general para decidir los costos, conforme a la definición del artículo 43 y del Apéndice III del Reglamento de la CCE.

Observaciones adicionales sobre los costos

La CCE prevé que los costos resultantes de los servicios de archivo corran a cargo de las partes, pero reconoce que aún no se han abordado cuestiones básicas relacionadas con la reglamentación de los costos. Por consiguiente, la CCE no puede prever en este momento con exactitud las eventuales repercusiones de esos costos en la aplicación del Reglamento de la CCE.

En el párrafo 5) de su artículo 43, el Reglamento de la CCE dispone que el tribunal arbitral distribuirá los costos del arbitraje entre las partes, tomando en consideración el resultado del caso y otras circunstancias relevantes. Conforme al párrafo 1) del artículo 43 del Reglamento de la CCE, esos costos abarcan los honorarios del tribunal arbitral, el arancel administrativo de la CCE y los gastos del tribunal arbitral y de la CCE. Como se explica en el artículo 4 del Apéndice III del Reglamento de la CCE, los “gastos” incluyen “todo gasto razonable en que haya incurrido el árbitro o los árbitros y la CCE”.

La CCE agradece a la CNUDMI la oportunidad que le ha ofrecido para contribuir a su misión y espera poder seguir analizando el tema en el Grupo de Trabajo.

**D. Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales:
preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los
arbitrajes entablados entre inversionistas y Estados en el marco de un
tratado — Propuesta presentada por los Gobiernos de la Argentina,
Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, México,
Noruega y Sudáfrica, presentada al Grupo de Trabajo sobre
Arbitraje y Conciliación en su 57º período de sesiones**

(A/CN.9/WG.II/WP.174)

[Original: inglés]

Índice

Párrafos

I.	Introducción.	1
II.	Propuesta de los Gobiernos de la Argentina, Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, México, Noruega y Sudáfrica	

I. Introducción

1. En el 56º período de sesiones del Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación), se invitó a las delegaciones a coordinar sus esfuerzos para proponer soluciones relativas a la determinación del ámbito de aplicación del proyecto de reglamento sobre la transparencia distintas de la propuesta contenida en el párrafo 54 del documento A/CN.9/741 y a comunicar a la secretaría sus propuestas de redacción al respecto para que las examinara el Grupo de Trabajo (A/CN.9/741, párr. 59). Los Gobiernos de la Argentina, Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, México, Noruega y Sudáfrica presentaron una propuesta cuyo texto se reproduce a continuación en la forma en que lo recibió la secretaría.

II. Propuesta de los Gobiernos de la Argentina, Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, México, Noruega y Sudáfrica

Original: inglés

Fecha: 1 de agosto de 2012

Aplicación del reglamento sobre la transparencia a los tratados de inversiones ya existentes

En el informe del Grupo de Trabajo II sobre la labor de su 56º período de sesiones (A/CN.9/741), celebrado en Nueva York del 6 al 10 de febrero de 2012, se aborda la cuestión de la aplicabilidad del nuevo reglamento sobre la transparencia en el marco de los tratados de inversiones ya existentes, es decir, los concertados antes de la [fecha de aprobación] [fecha de entrada en vigor] del reglamento sobre la transparencia. Véanse, por ejemplo, los párrafos 50 a 53 del documento

A/CN.9/741, que demuestran que hubo discrepancias de opinión sobre esta cuestión en el Grupo de Trabajo.

En el párrafo 54 de dicho documento se dice que “se invitó al Grupo de Trabajo a que adoptara el siguiente criterio ... Para los tratados de inversiones ya existentes, el reglamento sobre la transparencia solo sería aplicable cuando las partes hubieran consentido expresamente en ello, y su redacción dejaría en claro que no podría haber ninguna interpretación dinámica de los tratados de inversiones existentes que permitiera aplicarles el reglamento sobre la transparencia”.

Podrá haber “interpretación dinámica” de un tratado de inversiones cuando tal tratado, interpretado conforme a las disposiciones aplicables para su interpretación, prevea la aplicación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI en la forma en que este evolucione con el tiempo, por lo que, en el marco de ese tratado, será posible aplicar una versión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI [aprobada] [que entre en vigor] en fecha posterior a la celebración de dicho tratado, por ejemplo “el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en la fecha de la notificación del arbitraje”.

El informe indica claramente que varias delegaciones no estuvieron de acuerdo con el criterio propuesto en párrafo 54. Por ejemplo, en el párrafo 56 se dice: “Se reiteraron las siguientes opiniones divergentes: por una parte, se consideró que el párrafo 1 del artículo 1 debería dejar abierta la posibilidad de la aplicación judicial del reglamento sobre la transparencia a los tratados vigentes, o que nada de lo dispuesto en el reglamento debería prohibir esa aplicación ...”. Además, el párrafo 58 contiene el siguiente texto: “Unas pocas delegaciones reiteraron que la interpretación dinámica era jurídicamente admisible y que no estaban dispuestas a aceptar una ‘prohibición general’ que impidiera la efectiva aplicación de las disposiciones en los arbitrajes derivados de tratados de inversiones que hubieran previsto beneficiar a las partes con las disposiciones más modernas del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, que en este caso serían las disposiciones sobre la transparencia”.

El párrafo 59 del documento A/CN.9/741 estipula, en su totalidad, lo siguiente:

Se aclaró que aquellas delegaciones que tuvieran dificultad en aceptar la propuesta enunciada en el párrafo 54 y que aún desearan proponer otra solución (ya fuera a favor de un criterio de adhesión o una interpretación dinámica), tendrían la posibilidad de hacerlo en el próximo período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre la base de las propuestas enunciadas en el párrafo 8 del documento A/CN.9/WG.II/WP.169. Se señaló que algunas delegaciones habían indicado la posibilidad de encontrar una redacción que permitiera a los Estados que desearan excluir toda posibilidad de interpretación dinámica de sus tratados tener certeza al respecto, pero manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de que otros Estados adoptaran una interpretación dinámica. Se invitó a esas delegaciones a coordinar sus esfuerzos y a comunicar a la Secretaría sus propuestas de redacción al respecto para que las examinara el Grupo de Trabajo.

Este documento se presenta en respuesta a esa invitación.

Los copatrocinadores indicados *supra* se han guiado, al prepararlo, por ciertos principios fundamentales:

1. La Comisión, en sus 44° y 45° períodos de sesiones, reiteró su compromiso respecto de la importancia de garantizar la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado¹.
2. Para promover la transparencia con efectividad es esencial considerar los tratados de inversiones vigentes actualmente en el plano internacional².
3. La aplicación del reglamento sobre la transparencia en el marco de un tratado de inversiones ya existente se supedita al acuerdo de las partes en ese tratado.
4. En la mayoría de los casos se verá claramente si en un tratado ya existente no se contempló la aplicación del reglamento sobre la transparencia y, cuando ello no esté claro, las partes en el tratado podrán adoptar medidas para impedir tal aplicación si así lo desean.
5. Ahora bien, quienes no desean que el reglamento sobre la transparencia se aplique en el marco de sus tratados no deberían intentar hacer obligatorio un efecto análogo en los casos en que otros deseen que el reglamento sobre la transparencia se aplique en el marco de sus tratados y la redacción de estos prevea dicha aplicación. Abogar por otra cosa sería desleal y no estaría en consonancia con el mandato impartido por la Comisión.
6. Además, el reglamento sobre la transparencia no puede pretender establecer disposiciones de interpretación de los tratados, los cuales se rigen por el derecho internacional, incluidas las estipulaciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Teniendo presentes estos principios, se propone la siguiente redacción del artículo 1 del proyecto de reglamento sobre la transparencia:

Si un tratado concertado antes de la [fecha de aprobación/fecha de entrada en vigor del reglamento sobre la transparencia] remite al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, esa remisión denotará la versión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI que lleve incorporado el reglamento sobre la transparencia siempre que el tratado, interpretado en conformidad con el derecho internacional, refleje que las partes en el mismo están de acuerdo en aplicar esa versión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Las partes podrán convenir también, tras la [fecha de aprobación/fecha de entrada en vigor del reglamento sobre la transparencia], en aplicar dicho reglamento sobre la transparencia el marco de un tratado concertado antes de esa fecha.

¹ Véase, por ejemplo, *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17)*, párr. 200 (el cual dice que la Comisión “reiteró el compromiso que había contraído en su 41° período de sesiones de 2008 acerca de la importancia de que se garantizara la transparencia en ese tipo de arbitrajes” y se citan los *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1)*, párr. 314.

² Véase id. (donde se puntualiza que la Comisión “confirmó que la cuestión de la aplicabilidad de la norma jurídica sobre la transparencia a los tratados de inversiones existentes formaba parte del mandato del Grupo de Trabajo y era una cuestión que revestía un gran interés práctico, habida cuenta del gran número de tratados ya concertados”).

Este criterio responde a los intereses de todos los involucrados. Se funda en el consentimiento de las partes en el tratado de inversiones. Si las partes en el tratado de inversiones discrepan en la cuestión de si debe interpretarse que el tratado prevé la aplicación del reglamento sobre la transparencia, ello es un asunto que ha de resolver un tribunal o corte de justicia en conformidad con las disposiciones pertinentes de interpretación de los tratados conforme al derecho internacional; el reglamento sobre la transparencia no puede dictar ese resultado.

**E. Informe del Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación
sobre la labor realizada en su 58º período de sesiones
(Nueva York, 4 a 8 de febrero de 2013)**

(A/CN.9/765)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-4
II. Organización del período de sesiones	5-12
III. Deliberaciones y decisiones	13-14
IV. Preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	15-94
A. Examen de las cuestiones sustantivas pendientes en relación con el proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	15-66
1. Artículo 1 - Ámbito de aplicación	16-40
2. Artículo 5 - Alegatos presentados por una parte en el tratado que no sea litigante	41-51
3. Artículo 6 - Audiencias	52-57
4. Artículo 7 - Excepciones a la norma de transparencia	58-66
B. Propuestas para resolver cuestiones sustantivas pendientes en relación con el proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	67-80
1. Propuestas	67-71
2. Examen de las propuestas	72-74
3. Propuesta de transacción revisada	75-80
C. Establecimiento de un registro de la información publicada	81-88
1. Institución(es) que desempeñará(n) la función de registro	81-85
2. Documentos en papel	86
3. Directrices	87
4. Exención de responsabilidad	88
D. Examen de cuestiones de redacción pendientes relativas al proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	89-94
1. Artículo 2 - Publicación de información tras el inicio del procedimiento arbitral	90
2. Artículo 3 - Publicación de documentos	91-94
V. Otros asuntos	95-98

I. Introducción

1. En su 43º período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010), la Comisión, respecto de la futura labor sobre la solución de las controversias comerciales, recordó la decisión que había adoptado en su 41º período de sesiones (Nueva York, 16 de junio a 3 de julio de 2008)¹ de que, una vez concluida la revisión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, se abordara, con carácter prioritario, el tema de la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado. La Comisión encomendó a su Grupo de Trabajo II la tarea de preparar una norma jurídica sobre ese tema².

2. En su 44º período de sesiones (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011), la Comisión reiteró el compromiso que había expresado en su 41º período de sesiones acerca de la importancia de que se garantizara la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado. La Comisión confirmó que la cuestión de la aplicabilidad de la norma jurídica sobre la transparencia a los tratados de inversiones existentes formaba parte del mandato del Grupo de Trabajo y era una cuestión que revestía un gran interés práctico, habida cuenta del gran número de tratados ya concertados³. Además, la Comisión convino en considerar que la cuestión de una posible intervención en el arbitraje de un Estado no litigante pero que fuera parte en el tratado de inversiones entraba en el mandato del Grupo de Trabajo. La cuestión de si la norma jurídica sobre la transparencia debía o no ocuparse de ese derecho de intervención y, en caso afirmativo, la determinación del alcance y de las modalidades de tal intervención debería ser objeto de un examen más a fondo por parte del Grupo de Trabajo⁴.

3. En su 45º período de sesiones (Nueva York, 25 de junio a 6 de julio de 2012), la Comisión reafirmó la importancia de que se garantizara la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, como había señalado en su 41º período de sesiones, en 2008, y en su 44º período de sesiones, en 2011⁵, e instó al Grupo de Trabajo a que siguiera esforzándose y concluyera su labor relativa al reglamento sobre la transparencia para que la Comisión lo examinara, preferiblemente en su siguiente período de sesiones⁶.

4. En el documento A/CN.9/WG.II/WP.175, párrs. 5 a 14, figura la recopilación más reciente de referencias históricas sobre el examen de la labor del Grupo de Trabajo por parte de la Comisión.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1), párr. 314.*

² *Ibid.*, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), párr. 190.

³ *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 200.

⁴ *Ibid.*, párr. 202.

⁵ *Ibid.*, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1), párr. 314, y sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 200, respectivamente.

⁶ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 69.

II. Organización del período de sesiones

5. El Grupo de Trabajo, integrado por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 58º período de sesiones en Nueva York, del 4 al 8 de febrero de 2013. Asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Croacia, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Grecia, India, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, Kenya, Mauricio, México, Nigeria, Noruega, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Singapur, Tailandia, Turquía y Venezuela (República Bolivariana de).

6. Asistieron al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Angola, Belarús, Bélgica, Burkina Faso, Chipre (República de), Ecuador, Eslovaquia, Finlandia, Indonesia, Irlanda, Kuwait, Omán, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Qatar, Rumania, Suecia, Suiza y Túnez.

7. Asistieron al período de sesiones observadores de los siguientes Estados y Entidades que no son miembros: Santa Sede.

8. Asistieron al período de sesiones observadores de la Unión Europea.

9. Asistieron además al período de sesiones observadores de las siguientes organizaciones internacionales:

a) *Sistema de las Naciones Unidas*: Banco Mundial, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Oficina de Asuntos Jurídicos/División de Asuntos Jurídicos Generales y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);

b) *Organizaciones intergubernamentales*: Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y Tribunal Permanente de Arbitraje;

c) *Organizaciones no gubernamentales invitadas*: American Bar Association (ABA), Asociación Árabe para el Arbitraje Internacional (AAIA), Asociación de Arbitraje de los Estados Unidos/International Centre for Dispute Resolution (AAA/ICDR), Asociación Internacional de Abogados (IBA), Asociación Sueca de Arbitraje (SAA), Association of the Bar of the City of New York (ABCNY), Association Suisse de l'Arbitrage (ASA), Barreau de Paris, Center for International Environmental Law (CIEL), Centro Belga para el Arbitraje y la Mediación (CEPANI), Centro Regional de Arbitraje de Teherán (TRAC), Chartered Institute of Arbitrators (CIARB), Club de Árbitros de la Cámara de Arbitraje de Milán, Comisión Internacional de Arbitraje Económico y Comercial de China (CIETAC), Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial (ICCA), Construction Industry Arbitration Council (CIAC), Corporate Counsel International Arbitration Group (CCIAG), Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje Comercial (IFCAI), Forum for International Conciliation and Arbitration C.I.C. (FICACIC), Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), Instituto de Arbitraje Internacional (IAI), Instituto de Derecho Mercantil Internacional (IICL), Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), International Insolvency

Institute (III), Miami International Arbitration Society (MIAS), Moot Alumni Association of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (MAA), New York State Bar Association (NYSBA), P.R.I.M.E. Finance Foundation (P.R.I.M.E.), Queen Mary University of London School of International Arbitration (QMUL), Tribunal de Arbitraje de Madrid y Tribunal Internacional de Arbitraje.

10. El Grupo de Trabajo eligió las siguientes autoridades:

Presidente: Sr. Salim Moollan (Mauricio)

Relator: Sr. David Brightling (Australia).

11. El Grupo de Trabajo tuvo a su disposición los siguientes documentos: a) el programa provisional (A/CN.9/WG.II/WP.175); b) notas de la Secretaría relativas a la preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado de inversiones (A/CN.9/WG.II/WP.176 y su adición; y A/CN.9/WG.II/WP.177).

12. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:

1. Apertura del período de sesiones.
2. Elección de la Mesa.
3. Aprobación del programa.
4. Preparación de una norma jurídica acerca de la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado.
5. Otros asuntos.
6. Aprobación del informe.

III. Deliberaciones y decisiones

13. El Grupo de Trabajo reanudó su labor sobre el tema 4 del programa basándose en las notas preparadas por la Secretaría (A/CN.9/WG.II/WP.176 y su adición; A/CN.9/WG.II/WP.177). Las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo en relación con este tema del programa se recogen en el capítulo IV. Las deliberaciones del Grupo de Trabajo en relación con otros asuntos se recogen en el capítulo V.

14. Al concluir sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría: i) que preparara un proyecto de reglamento revisado sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado basándose en las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo, y que, a ese respecto, efectuase los ajustes de redacción necesarios para garantizar la concordancia del lenguaje en el texto del reglamento; ii) que distribuyera entre los gobiernos el proyecto de reglamento revisado sobre la transparencia para que formularan sus observaciones, a fin de que la Comisión pudiera examinar y aprobar el proyecto de reglamento revisado en su 46º período de sesiones, que se celebraría en Viena del 8 al 26 de julio de 2013; y iii) que preparara una nota a la Comisión para su examen en la que figurase el proyecto de texto de una convención sobre la transparencia, proyectos de recomendaciones y declaraciones modelo, en relación con la cuestión de la aplicación del reglamento sobre la transparencia a las

controversias surgidas en el marco de tratados de inversiones concertados antes de su aprobación (véase A/CN.9/WG.II/WP.176/Add.1, párrs. 14 a 34).

IV. Preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado

A. Examen de las cuestiones sustantivas pendientes en relación con el proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado

15. El Grupo de Trabajo recordó las cuestiones sustantivas que habían quedado pendientes para su examen como parte de la tercera lectura del reglamento sobre la transparencia, que se enumeraban en el párrafo 6 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176 (véase también A/CN.9/760, párrs. 123 y 124), y acordó examinar primero esas cuestiones.

1. Artículo 1 - Ámbito de aplicación

16. El Grupo de Trabajo examinó el artículo 1, que figuraba en el párrafo 7 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176 y, habiendo acordado que examinaría las cuestiones sustantivas pendientes, procedió a examinar el párrafo 1) de dicho artículo.

Párrafo 1) - Aplicabilidad de la norma jurídica sobre la transparencia

17. El Grupo de Trabajo recordó los enfoques examinados en sus períodos de sesiones 56° y 57° en relación con el párrafo 1). Se recordó que había recibido amplio apoyo, tras la correspondiente transacción, la solución relativa a la fecha de concertación del tratado según la cual en los tratados concertados después de la entrada en vigor del reglamento sobre la transparencia las partes contratantes deberían indicar expresamente si optaban por no aplicar el reglamento y en los tratados preexistentes deberían señalar expresamente si optaban por aplicarlo (véase A/CN.9/741, párr. 54).

18. Se afirmó que ni la opción 1 ni la 3 (en el párrafo 7 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176) reflejaban suficientemente el acuerdo al que se había llegado.

19. Se dijo también que, si bien la propuesta formulada en el 57° período de sesiones del Grupo de Trabajo, que se presentaba como variante 2 (en el párrafo 7 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176), reflejaba en algunos aspectos la transacción mencionada en el párrafo 17 del presente documento, lo cierto es que no daba suficiente cabida a las opiniones de las delegaciones que reconocían que el reglamento sobre la transparencia podría aplicarse en el marco de los tratados existentes que se remitían al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, en particular en los casos en que la intención de dichos tratados -manifiesta expresamente por el lenguaje contenido en ellos- fuera incorporar las enmiendas que se fueran introduciendo en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente según fuera este evolucionando.

Primera propuesta relativa al párrafo 1)

20. Por consiguiente, y con miras a reconciliar ese punto de vista con el proyecto de texto existente de la variante 2, una delegación presentó una nueva propuesta para reemplazar el párrafo 1) en su totalidad, que decía lo siguiente (“propuesta relativa al artículo 1 1)”):

“1. El Reglamento sobre la Transparencia se aplicará a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas (“el tratado”) celebrado después de [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia], a menos que las partes en el tratado hayan acordado otra cosa. 2. En los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado celebrado antes de [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia] que no prevea expresamente la aplicación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI ‘enmendado’, ‘revisado’ o ‘en vigor en el momento de presentarse de la demanda’ ni utilice lenguaje con significado y efectos similares, el presente Reglamento solamente se aplicará si: a) la partes litigantes convienen en su aplicación respecto de ese arbitraje; o, b) las partes en el tratado o, en el caso de un tratado multilateral, el Estado de origen del inversionista y el Estado demandado han acordado su aplicación después de [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia]. 3. El presente Reglamento no afectará a la autoridad que de otro modo puedan tener los tribunales arbitrales conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI para dirigir el arbitraje de forma que se promueva la transparencia, por ejemplo aceptando alegatos de terceros. 4. El presente Reglamento se podrá utilizar en arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados con arreglo a otros reglamentos de arbitraje o en procedimientos especiales.”

21. Se aclaró en la introducción de esa propuesta que la intención era equilibrar los diferentes puntos de vista que se habían expresado en el seno del Grupo de Trabajo y que se partía de la base de dos factores objetivos fundamentales, que se describieron de la siguiente manera: i) el momento de la concertación de un tratado y, concretamente, si este se concertaba antes o después de la entrada en vigor del reglamento sobre la transparencia; y ii) la autonomía de las partes en un tratado, según la cual estas podrían determinar si aplicarían o no el reglamento sobre la transparencia a los litigios que surgieran en relación con ese tratado.

22. Se dijo a modo de resumen que la propuesta relativa al artículo 1 1) mantenía la transacción a que se hace referencia en el párrafo 17 al exigir que las partes en el tratado indicaran expresamente si optaban por aplicar el reglamento sobre la transparencia, en el caso de tratados en los que ya fueran partes, y si optaban por no aplicarlo, en el caso de tratados concertados después de la entrada en vigor del reglamento. Se aclaró además que la única categoría de tratados a la que se podría aplicar el reglamento sobre la transparencia en virtud de la propuesta relativa al artículo 1 1), categoría que no se había recogido anteriormente en la propuesta de transacción que figuraba como variante 2 del párrafo 7 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176, era la de los tratados preexistentes que incluyeran lenguaje específico sobre la evolución del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI,

por ejemplo, los que hicieran referencia al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI “enmendado”, “revisado” o “en vigor en el momento de presentarse la demanda”.

23. Se señaló además, como información de referencia, que los nuevos párrafos 3) y 4) de la propuesta no eran, en principio, polémicos, dado que el párrafo 3) simplemente aseguraba que las nuevas facultades otorgadas en virtud del reglamento sobre la transparencia no afectarían a los poderes de decisión de los tribunales arbitrales previstos en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI; y el párrafo 4) reafirmaba el principio establecido en el párrafo 3) del artículo 1 del proyecto de reglamento sobre la transparencia (en el párrafo 7 de A/CN.9/WG.II/WP.176), a saber, que el reglamento sobre la transparencia podría utilizarse en combinación con cualquier reglamento de arbitraje aplicable.

24. El Grupo de Trabajo procedió a examinar la propuesta relativa al artículo 1 1), tanto las cuestiones de política que planteaba como, como asunto secundario, las mejoras de redacción que pudieran ser necesarias para aclarar la propuesta.

Cuestiones de política

25. Se expresaron opiniones de que una remisión en un tratado al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI “enmendado”, o una expresión similar, no debía bastar para que el reglamento sobre la transparencia fuera aplicable. En concreto, se dio el ejemplo de un tratado concertado en un momento en el que los arbitrajes se celebraban en condiciones confidenciales y no se tenían muy en cuenta las normas de transparencia. En respuesta, se señaló que si un tratado preveía expresamente que se aplicara una versión actualizada del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, las partes en ese tratado habían previsto esa evolución en el momento de negociarlo. Se afirmó que, en esos casos, debería ser posible aplicar el reglamento sobre la transparencia cuando el tribunal arbitral considerase que reflejaba el acuerdo alcanzado entre las partes en ese tratado. También se dijo que las expectativas de confidencialidad que pudieran tenerse en relación con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI eran específicas del arbitraje comercial y no se harían extensivas necesariamente a los litigios entre inversionistas y Estados.

26. Un gran número de delegaciones aceptaron que la propuesta relativa al artículo 1 1), que preveía la posibilidad de la aplicación del reglamento sobre la transparencia cuando el tratado utilizara un lenguaje expresamente dinámico que permitiera que se hicieran tales argumentos ante un tribunal arbitral, representaba una solución de compromiso clara, razonable y jurídicamente sólida, aunque no reflejase la variante que preferían para el artículo 1 1).

27. Muchas de esas delegaciones expresaron su apoyo preferente, en principio, a la solución de transacción mencionada en el párrafo 17, que no preveía la posibilidad de que los tribunales arbitrales aplicaran el reglamento sobre la transparencia en virtud de una interpretación dinámica de los tratados. Muchas otras delegaciones que apoyaban la propuesta relativa al artículo 1 1) por considerarla una transacción razonable explicaron que preferirían que el tribunal arbitral tuviera la facultad, como se formulaba en la variante 3 (en el párrafo 7 de A/CN.9/WG.II/WP.176), para aplicar el reglamento sobre la transparencia cuando se interpretara que el tratado, de conformidad con el derecho internacional, preveía esa aplicación. No obstante, en aras de alcanzar una transacción, y de adelantar con el proyecto de reglamento sobre la transparencia, muchas delegaciones que expresaron

apoyo preferente por la variante 2 o la variante 3 reconocieron que la propuesta relativa al artículo 1 1) enunciada en el párrafo 20 sería aceptable.

Segunda propuesta relativa al párrafo 1)

28. Tras un debate, se presentó una nueva propuesta (la “segunda propuesta”), que modificaba en cierta medida la propuesta relativa al artículo 1 1), a fin de lograr una mayor claridad en cuanto a su alcance y de despejar las dudas planteadas en el párrafo 25. La segunda propuesta consistiría en suprimir del preámbulo del párrafo 2) el siguiente texto: “que no prevea expresamente la aplicación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI ‘enmendado,’ ‘revisado,’ o ‘en vigor en el momento de presentarse la demanda’ ni utilice lenguaje con significado y efectos similares”. El preámbulo quedaría, por tanto, como sigue: “Con respecto a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado celebrado antes de [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia], el presente Reglamento solamente se aplicará si:”. Además, se añadiría un nuevo párrafo 2) c) que rezaría así: “el tribunal arbitral determina que el lenguaje del tratado que prevé la aplicación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI enmendado, revisado o en vigor en el momento de presentarse la demanda, o que tenga un significado y efectos similares, expresa el acuerdo de las partes contratantes de aplicar el Reglamento sobre la Transparencia.”

29. Se señaló que esa propuesta difería de la variante 3 puesto que limitaba la posibilidad de aplicar el reglamento sobre la transparencia sobre la base de una interpretación dinámica a los casos en que el lenguaje del tratado lo permitiera expresamente (“enmendado”, “revisado”, “en vigor en el momento de presentarse la demanda”, o expresiones de significado y efecto similares). También se dijo que esa propuesta aclaraba que los tribunales arbitrales tendrían facultad discrecional para aceptar alegatos en los que se indicara que era apropiado hacer tal interpretación dinámica, pero que no se aplicaría automáticamente el reglamento sobre la transparencia en todos los casos en que existiera lenguaje de ese tenor. Por último, se señaló que la formulación utilizada dejaba claro que la función del tribunal arbitral sería interpretar el tratado.

30. Una gran mayoría expresó apoyo a la “segunda propuesta”. El Grupo de Trabajo tomó nota de las sugerencias formuladas en relación con esa propuesta, que se reflejan en los párrafos 31 a 33 a continuación.

31. Como aclaración, en el Grupo de Trabajo hubo armonía de criterios en el sentido de que: i) cuando un tratado contenía normas sobre transparencia redactadas para que prevalecieran sobre el reglamento de arbitraje aplicable, las disposiciones sobre transparencia del tratado prevalecerían sobre las del reglamento sobre la transparencia de la CNUDMI, que a su vez prevalecería (como se prevé en el proyecto de artículo 1 3) del reglamento sobre la transparencia, véase el párrafo 7 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176) sobre cualquier disposición aplicable del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI; y ii) no se interpretara que lo dispuesto en el artículo 1 establecía normas sobre la interpretación de los tratados.

Párrafo 2) c) de la segunda propuesta

32. Se sugirió enmendar el párrafo 2) c) de la segunda propuesta a fin de aclarar que el tribunal arbitral no debía determinar por iniciativa propia si las disposiciones del tratado permitían la aplicación del reglamento sobre la transparencia sin previa solicitud de las partes al respecto. Una delegación expresó desacuerdo con esa sugerencia.

Relación entre el reglamento sobre la transparencia y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI

33. En respuesta a una pregunta sobre si el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI se modificaría para incluir una referencia al reglamento sobre la transparencia, se recordó al Grupo de Trabajo el proyecto de propuesta de modificación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, que figuraba en el párrafo 15 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176. Se sugirió que toda modificación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI fuera aplicable a partir de la fecha de entrada en vigor del reglamento sobre la transparencia, dado que una serie de tratados concertados desde 2010 incluían una referencia al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010, y las partes en esos tratados no tenían necesariamente la intención de incluir normas sobre transparencia.

Párrafo 2) - Aplicación del reglamento sobre la transparencia por las partes litigantes

34. El Grupo de Trabajo examinó el artículo 1, párrafo 2), contenido en el documento A/CN.9/WG.II/WP.176, párr. 7, que reflejaba el principio de que las partes litigantes no pueden establecer excepciones al reglamento sobre la transparencia salvo que así lo permita el tratado (A/CN.9/741, párrs. 60 a 81; A/CN.9/WG.II/WP.172, párr. 19; A/CN.9/WG.II/WP.176, párr. 17).

35. Se expresaron opiniones en el sentido de que tal vez tendría que ajustarse ligeramente el párrafo 2) b) para asegurar que se aclarasen las facultades otorgadas al tribunal arbitral de adaptar las normas a fin de lograr los objetivos de transparencia, con objeto de evitar que esas facultades constituyeran una excepción adicional al reglamento (como las establecidas en el artículo 7), lo cual, se afirmó, no era la intención de dicha disposición. Antes bien, el párrafo 2) b) tenía únicamente el propósito de otorgar al tribunal arbitral cierta flexibilidad para adaptar el reglamento si así lo exigían las circunstancias del procedimiento. El Grupo de Trabajo encomendó a la Secretaría que hiciera las modificaciones necesarias en el texto teniendo en cuenta ese objetivo.

36. En todos los demás aspectos, el Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en cuanto al fondo del artículo 1, párrafo 2).

Párrafo 3) - Relación entre el reglamento sobre la transparencia y el Reglamento de arbitraje aplicable

37. El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en cuanto al fondo del artículo 1, párrafo 3), tal como figura en el párrafo 7 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176.

Párrafo 4) - Relación entre el reglamento sobre la transparencia y el derecho aplicable

38. El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en cuanto al fondo del artículo 1, párrafo 4), tal como figura en el párrafo 7 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176.

Párrafo 5) - Discrecionalidad del tribunal arbitral

39. El Grupo de Trabajo recordó que, en su 56º período de sesiones, había estado de acuerdo en cuanto al fondo del artículo 1, párrafo 5), relativo a la discrecionalidad del tribunal arbitral de conformidad con el reglamento (A/CN.9/741, párr. 85).

Nota de pie de página del artículo 1, párrafo 1)

-“tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas”

40. El Grupo de Trabajo recordó que, en su 56º período de sesiones, había estado de acuerdo en cuanto al fondo de la nota de pie de página del artículo 1, que tenía la finalidad de aclarar que la idea de que el reglamento sobre la transparencia era aplicable a los tratados debía interpretarse en sentido amplio (A/CN.9/741, párr. 102).

2. Artículo 5 - Alegatos presentados por una parte en el tratado que no sea litigante

41. El Grupo de Trabajo examinó el artículo 5 que figuraba en el párrafo 38 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176, en el que se preveían los alegatos de una parte en el tratado que no fuera litigante. En particular, en su 57º período de sesiones, el Grupo de Trabajo determinó que el párrafo 1) de ese artículo requería un examen más a fondo por el Grupo de Trabajo (A/CN.9/760, párr. 124; A/CN.9/WG.II/WP.176, párr. 6).

Párrafo 1)

42. El Grupo de Trabajo examinó la cuestión de si el tribunal arbitral debía o no aceptar alegatos de una parte en el tratado que no fuera litigante, o contar con facultades discrecionales para hacerlo, y, en consecuencia, si debían utilizarse las palabras “permitirá” o “podrá permitir” en el párrafo 1) (véase A/CN.9/WG.II/WP.176, párr. 40).

43. Se expresó apoyo a la utilización de las palabras “podrá permitir”, dado que se daría al tribunal arbitral la discrecionalidad de aceptar alegatos hechos por una parte en el tratado que no fuera litigante, promoviendo de ese modo un enfoque más flexible al permitir, por ejemplo, que el tribunal arbitral rechazara alegatos presentados en una etapa tardía del procedimiento, cuando esos alegatos perturbaran el curso de las actuaciones.

44. También se expresó apoyo al principio de que un tribunal arbitral aceptara alegatos hechos por una parte en el tratado que no fuera litigante y, en consecuencia, a la utilización de la palabra “permitirá”. Se manifestó que el hecho de aceptar alegatos de partes en el tratado que no fueran litigantes garantizaría que se ofreciera una información equilibrada y completa al tribunal arbitral y que todas las opiniones constaran en acta, y que el tribunal arbitral podría en todo caso dar a ese alegato la importancia que estimara conveniente. Además, se observó que cuando una parte en

el tratado que no fuera litigante hiciera un alegato, sería inusual o poco probable que el tribunal arbitral la rechazara.

45. En respuesta a una invitación del Grupo de Trabajo a los Estados para que examinaran sus tratados a fin de determinar si contenían disposiciones que otorgaran a una parte no litigante el derecho a presentar al tribunal una opinión sobre la interpretación del tratado (A/CN.9/760, párr. 63), se dijo que los tratados no se pronunciaban sobre la cuestión o incluían la palabra “permitirá” (a ese respecto, se mencionaron como ejemplos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica). Además, se dijo que añadir un elemento discrecional podría suponer una desviación de la práctica actual y un debilitamiento de las normas futuras en la materia.

46. Se expresó la opinión de que la distinción propuesta en cuanto a que el tribunal arbitral gozara o no de la discrecionalidad de aceptar alegatos de una parte en el tratado que no fuera litigante no era pertinente en la práctica. Se dijo que una parte no litigante podría presentar alegatos por iniciativa propia tanto si se utilizaban las palabras “podrá permitir” o “permitirá” como si no, y que el tribunal arbitral les daría en todo caso el trámite que estimara conveniente. En respuesta, se manifestó que podrían plantearse situaciones en que se justificara el rechazo de un alegato. Por consiguiente, era sin duda necesario reglamentar esa cuestión con cierta flexibilidad, en particular para ocuparse de situaciones como las planteadas por alegatos tardíos que perturbaran el curso de las actuaciones.

47. Se dijo que la utilización de la palabra “permitirá” no excluía esa flexibilidad, cuando el párrafo 1) se leía conjuntamente con el párrafo 4), que preveía que el tribunal arbitral se cerciorara de que ningún alegato perturbara el curso de las actuaciones ni les impusiera una carga innecesaria, ni causara algún perjuicio indebido a ninguna de las partes litigantes.

48. Se plantearon dos preocupaciones con respecto a este enfoque. En primer lugar, se dijo que la palabra “permitirá” podría dar a entender que el tribunal arbitral estaba impedido de ejercer cualquier facultad discrecional en virtud del párrafo 4) cuando la perturbación fuera causada, por ejemplo, por un alegato muy tardío. En segundo lugar, se dijo que la segunda parte del párrafo 4), que trataba la cuestión del perjuicio causado por un alegato a alguna de las partes litigantes, podría no ser aplicable en lo que respecta al párrafo 1), dado que podría considerarse que todo alegato relativo a la interpretación del tratado afectaba a la situación de una parte en el litigio.

49. En respuesta a las preocupaciones planteadas en el párrafo 48 se dijo que i) podría insertarse texto para aclarar que el párrafo 4) se aplicaba, incluso cuando se utilizara la palabra “aceptará”, y ii) el límite establecido en el párrafo 4) no se refería a la posibilidad de causar algún perjuicio, sino que se situaba en un nivel superior que consideraba la posibilidad de que se derivara un perjuicio “inequitativo” de ese alegato.

50. Se expresó la opinión de que la capacidad del tribunal arbitral de invitar a la parte no litigante a formular alegatos con respecto a la interpretación del tratado podría menoscabar los derechos de la otra parte en ese tratado.

51. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en que el tribunal arbitral aceptara alegatos de una parte en el tratado que no fuera litigante, siempre que esos alegatos

no perturbaran el curso de las actuaciones ni les impusieran una carga innecesaria, ni causaran algún perjuicio inequitativo a ninguna de las partes litigantes. El Grupo de Trabajo también convino en que la palabra “aceptará” era más clara que la palabra “permitirá” en relación con los alegatos, y que el texto debía enmendarse en consecuencia. Así pues, el Grupo de Trabajo convino en modificar el párrafo 1) para que su texto fuera el siguiente: “1. El tribunal arbitral aceptará, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4), de partes en el tratado que no sean litigantes alegatos sobre cuestiones relacionadas con la interpretación del tratado, o bien, tras celebrar consultas con las partes litigantes, podrá invitarlas a que las hagan”.

3. Artículo 6 - Audiencias

52. El Grupo de Trabajo examinó el proyecto de artículo 6 que figuraba en el párrafo 44 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176. En particular, en su 57º período de sesiones, el Grupo de Trabajo había observado que necesitaba examinar más a fondo el párrafo 1) de ese artículo (A/CN.9/760, párr. 124; A/CN.9/WG.II/WP.176, párr. 6), por lo que reanudó su examen de ese párrafo.

Párrafo 1)

53. En su 57º período de sesiones, el Grupo de Trabajo había expresado considerable apoyo al principio de que la regla supletoria siguiera siendo que, de conformidad con el reglamento sobre la transparencia, las audiencias fueran públicas, a reserva únicamente de las excepciones establecidas en los párrafos 2) y 3) (A/CN.9/760, párr. 82). Se aclaró que el texto del párrafo 1) en relación con el cual el Grupo de Trabajo había acordado proceder en ese sentido en su 57º período de sesiones debía decir: “A reserva de lo dispuesto en el artículo 6, párrafos 2 y 3, las audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales (‘audiencias’) serán públicas.” La formulación que figuraba en el párrafo 44 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176 no reflejaba correctamente ese acuerdo.

54. En el 57º período de sesiones del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones habían apoyado, en cambio, la opinión de que cada parte litigante debía tener el derecho unilateral a que las audiencias se celebraran a puerta cerrada (A/CN.9/760, párr. 79). Esa propuesta no recibió apoyo en el período de sesiones en curso del Grupo de Trabajo. En cambio, se propuso como alternativa que las audiencias se celebraran en sesión privada si así lo acordaban ambas partes litigantes.

55. Se expresó considerable apoyo al texto establecido en el párrafo 53. Se dijo que las excepciones a que estaba sujeta la norma general sobre audiencias públicas, establecidas en los párrafos 2) y 3) del artículo 6, no solo creaban un régimen equilibrado y protegían intereses que pudieran ser confidenciales o perjudiciales para la integridad del proceso de arbitraje, sino que además daban cabida a toda objeción válida a la celebración de audiencias públicas. Se afirmó también que el mandato del Grupo de Trabajo al elaborar el reglamento sobre la transparencia era crear una norma que previese un nivel distinto, más elevado, de transparencia que el actual Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, que preveía como regla supletoria que las audiencias se celebraran a puerta cerrada (véase el artículo 25 4) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976 y el artículo 28 3) del Reglamento de 2010). Se expresó la opinión de que introducir una discrepancia entre los niveles de transparencia en la publicación de documentos conforme al artículo 3 y la disposición revocable relativa a las audiencias públicas en el artículo 6 podría llevar

a que las partes litigantes eludieran las normas de transparencia. Se señaló que las partes litigantes podrían evitar presentar documentos sujetos a la norma de transparencia y plantear en cambio esas cuestiones en audiencias celebradas a puerta cerrada. Se señaló también que en el artículo 1, párrafo 2), se disponía que las partes litigantes no podían apartarse del reglamento sobre la transparencia a menos que el tratado se lo permitiera, y que permitir que se apartaran por acuerdo contractual de la norma general de audiencias públicas en el reglamento sobre la transparencia sería incompatible con ese artículo.

56. También se expresó apoyo a la propuesta enunciada en el párrafo 54, a saber, que las audiencias fueran privadas cuando ambas partes litigantes así lo acordaran. Se afirmó que esa propuesta era una solución de transacción, en la medida en que se alejaba de la sugerencia anterior del derecho de veto unilateral, y que facilitaría la solución de controversias por las partes litigantes. Se dijo que la propuesta establecía un correcto equilibrio en el reglamento sobre la transparencia, habida cuenta de las demás disposiciones, por ejemplo, sobre publicación, notificaciones, alegatos, laudos y transcripciones. También se señaló que las costas serían menores para las partes litigantes si las audiencias fueran privadas. No recibió apoyo la idea de modificar la propuesta del veto conjunto para conceder al tribunal arbitral la discreción de anular el veto conjunto de las partes en los casos relacionados con los derechos humanos.

57. Se invitó a las delegaciones que apoyaban que como regla supletoria las audiencias fueran públicas, únicamente con las excepciones establecidas en los párrafos 2) y 3) del artículo 6, y a las delegaciones que apoyaban el derecho de veto conjunto con respecto a las audiencias públicas, a examinar si, como posible solución intermedia, el párrafo 1) que figuraba en el párrafo 44 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176 podría dar cabida a ambos enfoques. Ese texto preveía que las audiencias públicas fueran la regla supletoria, a reserva de las excepciones establecidas en los párrafos 2) y 3), y otorgaba además al tribunal arbitral la facultad de decidir otra cosa tras consultar con las partes litigantes. También se señaló que se aplicaría entonces el artículo 1, párrafo 5), a las facultades discrecionales del tribunal arbitral y los factores conexos que hubieran de tenerse en cuenta.

4. Artículo 7 - Excepciones a la norma de transparencia

58. El Grupo de Trabajo examinó el proyecto de artículo 7 contenido en el párrafo 1 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176/Add.1, que se refería a las excepciones a la norma de la transparencia. Concretamente, en su 57º período de sesiones, el Grupo de Trabajo había observado que necesitaría examinar más a fondo el párrafo 2) c) de ese artículo, así como un proyecto de propuesta de dos nuevos párrafos, numerados provisionalmente 2 d) y 2) *bis* (A/CN.9/760, párr. 123; A/CN.9/WG.II/WP.176, párr. 6).

Párrafo 2) c)

59. El Grupo de Trabajo examinó las tres variantes relativas al párrafo 2) c): i) la variante 1, conforme a la cual el tribunal arbitral realizaría un análisis de conflicto de leyes respecto de toda la información; ii) la variante 2, conforme a la cual el tribunal arbitral se remitiría a la legislación del demandado si se trataba de información del demandado, y a un análisis de conflicto de leyes respecto de toda la demás información; y iii) la variante 3, conforme a la cual se orientaba al tribunal

arbitral a que, en su análisis de conflicto de leyes respecto de cuestiones relacionadas con la información del demandado, tuviera particularmente en cuenta la legislación del demandado (A/CN.9/760, párr. 104).

60. Se expresó apoyo a la variante 1, al considerarse que era la que mejor se adaptaba a todas las distintas circunstancias que podían surgir en un arbitraje y que la legislación del demandado podría no ser la más adecuada en todos los casos. Se señaló a ese respecto que el tribunal arbitral era el que estaba en mejores condiciones de tomar una determinación tras analizar todas las circunstancias. Las delegaciones que estaban a favor de la variante 1 afirmaron que la variante 3 podría ser una solución de transacción aceptable en la medida en que, si bien dejaba claro que el tribunal arbitral debía tener en cuenta la legislación aplicable del demandado y, de esta forma, podía resultar aceptable para las delegaciones que preferían la variante 2, no imponía ninguna determinación en particular.

61. También se expresó apoyo a la variante 2. Se afirmó que debía protegerse la información presentada por el demandado contra su publicación conforme a la legislación aplicable del demandado. Se señaló que un demandado quedaría sujeto a su propia legislación en cualquier caso y que, a ese respecto, debía haber cierto grado de coherencia entre el arbitraje en el marco de tratados de inversiones y la legislación nacional.

62. Se expresó la opinión de que, según quedó constancia en el 57º período de sesiones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/760, párr. 103), la variante 2 se prestaba a abuso. Se recordó que el Grupo de Trabajo había expresado apoyo unánime a la propuesta de que no era aceptable que un Estado adoptara el reglamento sobre la transparencia en sus tratados de inversiones y utilizara luego su legislación interna para socavar el espíritu de ese reglamento. El Grupo de Trabajo reafirmó esa opinión por unanimidad.

Párrafo 2) d)

63. El Grupo de Trabajo examinó el párrafo 2) d), que se correspondía con una propuesta realizada en su 57º período de sesiones (A/CN.9/760, párr. 117).

64. No se expresó apoyo a ese párrafo, por lo que el Grupo de Trabajo convino en suprimirlo.

Párrafo 2) bis

65. El Grupo de Trabajo examinó el texto del párrafo numerado provisionalmente como 2) *bis*, que se correspondía con una propuesta realizada en su 57º período de sesiones (A/CN.9/760, párrs. 105 a 109). Se expresó cierto apoyo al párrafo 2) *bis* al considerarse que establecía una categoría de información distinta de la que se preveía en el párrafo 2) c) y que los intereses relativos a la seguridad eran lo suficientemente cruciales como para constituir excepciones cautelares en el reglamento sobre la transparencia no sujetas a revisión por procedimientos de arbitraje.

66. Se afirmó que el Grupo de Trabajo tenía el mandato de elaborar un reglamento sobre la transparencia y que el párrafo 2) *bis* representaba una excepción de amplio alcance que permitiría a los Estados eludir las normas de transparencia de forma

unilateral. En respuesta, se señaló que el texto que figuraba en ese párrafo se había utilizado en varios acuerdos de libre comercio y tratados bilaterales de inversiones.

B. Propuestas para resolver cuestiones sustantivas pendientes en relación con el proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado

1. Propuestas

67. Con miras a resolver las cuestiones sustantivas y normativas pendientes, se presentó una propuesta relativa a una posible transacción relacionada, por un lado, con el ámbito de aplicación del reglamento, y, por otro, con el nivel de transparencia que este establecería.

68. Se señaló que una transacción a este respecto podría consistir en: i) establecer una prescripción del artículo 1 con respecto a la aplicación del reglamento sobre la transparencia, de modo que no se aplicara a los tratados vigentes (salvo en la medida en que rigiera un instrumento para su aplicación, como los que figuran en los párrafos 14 a 34 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176/Add.1), y que el reglamento sobre la transparencia solo se aplicara a los tratados que se celebraran en el futuro cuando las partes en un tratado señalaran expresamente que optaban por su aplicación; y ii) mantener al mismo tiempo un alto grado de transparencia en las disposiciones sustantivas relativas a las audiencias públicas (artículo 6, párrafo 1)) y excepciones a la norma de la transparencia (artículo 7, párrafo 2)). Se señaló que de esa forma no sería necesario recurrir a soluciones de transacción en relación con el fondo del reglamento sobre la transparencia ni crear una norma de transparencia de nivel inferior, porque el reglamento solo se aplicaría en los casos en que las partes en un tratado así lo decidieran.

69. A ese respecto, se presentó la siguiente propuesta concreta que recogía un conjunto exhaustivo de disposiciones para resolver las cuestiones sustantivas y normativas que quedaban pendientes (la “propuesta de transacción”):

- i) Un nuevo proyecto de artículo 1 1) sobre la aplicabilidad del reglamento, con el siguiente texto: “1) El Reglamento sobre la Transparencia se aplicará a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas (“el tratado”) celebrado después de [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia], a menos que las partes en el tratado hayan acordado otra cosa. 2) En los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado celebrado antes de [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia], el presente Reglamento solamente se aplicará si: a) las partes litigantes convienen en su aplicación respecto de ese arbitraje; o, b) las partes en el tratado o, en el caso de un tratado multilateral, el Estado de origen del inversionista y el Estado demandado han acordado su aplicación después de [fecha de la entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia]. 3) El presente Reglamento no afectará a la autoridad que de otro modo puedan tener los tribunales arbitrales conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI

para dirigir el arbitraje de forma que se promueva la transparencia, por ejemplo, aceptando alegatos de terceros.”;

ii) El proyecto de artículo 6 1) diría lo siguiente: “1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 6, párrafos 2 y 3, las audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales (‘audiencias’) serán públicas.”;

iii) Se elegiría la variante 3 del artículo 7 2) c) que figuraba en el documento A/CN.9/WG.II/WP.176/Add.1, párr. 1; y

iv) Se modificaría el proyecto de artículo 7 2) *bis* para que dijera: “2) *bis*. Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento obligará a una parte litigante a facilitar [al público] información cuya divulgación estime que sería contraria a sus intereses de seguridad esenciales.”

70. Tras deliberar, se observó que había una amplia mayoría a favor de esa propuesta de transacción. Se invitó a las delegaciones que no pudieran aceptar esa propuesta a que i) determinaran si, llegado el caso, opondrían objeción formal a que se dejara constancia de que había habido consenso a favor de la propuesta de transacción, y ii) en paralelo, mantuvieran conversaciones con otras delegaciones.

71. Por consiguiente, las delegaciones que no podían aceptar la propuesta de solución de transacción enunciada en el párrafo 69 presentaron la siguiente nueva propuesta (la “contrapropuesta”): i) mantener el artículo 1 como se enuncia en el párrafo 69 i); ii) mantener el artículo 6 1) como se enuncia en la propuesta de solución de transacción en el párrafo 69 ii); iii) elegir la variante 2 del proyecto de artículo 7 2) c), en lugar de la variante 3, enunciada en la propuesta de solución de transacción; y iv) en el proyecto de artículo 7 2) *bis*, adoptar el texto de la propuesta de solución de transacción enunciado en el párrafo 69 iv), pero con una excepción más: concretamente, una excepción relativa a la información que impidiera la aplicación de la ley que, a diferencia de los intereses de seguridad esenciales mencionados en dicho párrafo, no dependiera de la determinación de las autoridades nacionales.

2. Examen de las propuestas

72. El Grupo de Trabajo examinó la propuesta de transacción que figura en el párrafo 69, así como la contrapropuesta que figura en el párrafo 71 del presente documento. Se añadieron nuevas manifestaciones de apoyo a la gran mayoría que expresó apoyo a la propuesta de transacción.

73. Se señaló que, en relación con ambas propuestas, las delegaciones habían hecho importantes concesiones, y al hacerlo se habían apartado de sus posiciones iniciales. En particular, se dijo que al examinar la contrapropuesta, las concesiones hechas por algunas delegaciones en la propuesta de transacción inicial podrían renegociarse únicamente sobre una base no global, artículo por artículo.

74. En vista de la gran mayoría que apoyaba la propuesta de transacción, se invitó a las delegaciones que no habían podido aceptarla a que respondieran si, no obstante el hecho de que la solución de transacción no representaba su solución preferida, podría aceptarse, de todos modos. Esas delegaciones solicitaron que se examinara más a fondo la contrapropuesta a fin de hallar puntos de convergencia con las delegaciones que apoyaban la propuesta de transacción.

3. Propuesta de transacción revisada

75. Tras celebrar consultas, el Grupo de Trabajo presentó una propuesta de transacción revisada (la “propuesta de transacción revisada”). A continuación figura el texto completo de los artículos de la propuesta de transacción revisada:

“Artículo 1

1) El Reglamento sobre la Transparencia se aplicará a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas (“el tratado”) celebrado después de [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia], a menos que las partes en el tratado hayan acordado otra cosa.

2) En los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado celebrado antes de [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia], el presente Reglamento solamente se aplicará si: a) las partes litigantes convienen en su aplicación respecto de ese arbitraje; o b) las partes en el tratado o, en el caso de un tratado multilateral, el Estado de origen del inversionista y el Estado demandado han acordado su aplicación después de [fecha de la entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia].

3) El presente Reglamento no afectará a la autoridad que de otro modo puedan tener los tribunales arbitrales conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI para dirigir el arbitraje de forma que se promueva la transparencia, por ejemplo, aceptando alegatos de terceros.

4) En todo arbitraje en que sea aplicable el Reglamento sobre la Transparencia de conformidad con un tratado o con un acuerdo concertado por las partes en ese tratado: a) Las [partes litigantes] [las partes en el arbitraje (las “partes litigantes”)] no podrán apartarse de ese Reglamento mediante acuerdo o de otro modo, a menos que el tratado se lo permita; b) El tribunal arbitral, al margen de las facultades discrecionales que le confieren algunas disposiciones del presente Reglamento, estará facultado para adaptar los requisitos de cualquier disposición concreta del presente Reglamento a las circunstancias del caso si ello resulta necesario para lograr en la práctica el objetivo de transparencia del Reglamento.

5) Siempre que el Reglamento sobre la Transparencia sea aplicable, complementará cualquier otro reglamento de arbitraje aplicable. Cuando exista un conflicto entre el Reglamento sobre la Transparencia y el reglamento de arbitraje aplicable, prevalecerá el Reglamento sobre la Transparencia. Sin perjuicio de cualquier otra disposición del presente Reglamento, cuando exista un conflicto entre el Reglamento sobre la Transparencia y el tratado, prevalecerán las disposiciones del tratado.

6) Cuando una norma del presente Reglamento esté en conflicto con una disposición del derecho aplicable al arbitraje de la que las partes no puedan apartarse, prevalecerá esa disposición.

7) Cuando el Reglamento sobre la Transparencia disponga que el tribunal arbitral tendrá facultades discrecionales, en el ejercicio de tales facultades el

tribunal arbitral tendrá en cuenta: a) el interés público en la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado y en el procedimiento arbitral en particular, y b) el interés de las partes litigantes en que la controversia se resuelva de manera justa y eficaz.

8) En presencia de toda conducta, medida u otro acto que tenga por efecto socavar enteramente los objetivos de transparencia del presente Reglamento, el tribunal arbitral garantizará la prevalencia de esos objetivos.

Nota de pie de página del artículo 1, párrafo 1):

* A los fines del Reglamento sobre la Transparencia, por “tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas”, se entenderá en sentido amplio todo acuerdo concertado entre Estados u organizaciones de integración regional, incluidos acuerdos de libre comercio, acuerdos de integración económica, acuerdos marco o de cooperación en materia de comercio o inversiones y tratados bilaterales y multilaterales de inversiones, siempre que estos contengan disposiciones sobre la protección de las inversiones o los inversionistas y el derecho de los inversionistas a recurrir al arbitraje contra las partes en el tratado.”

“Artículo 6

1) A reserva de lo dispuesto en el artículo 6, párrafos 2 y 3, las audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales (‘audiencias’) serán públicas.

2) Cuando sea necesario proteger la información confidencial o la integridad del proceso arbitral con arreglo a lo establecido en el artículo 7, el tribunal arbitral adoptará disposiciones para celebrar en privado la parte de la audiencia que deba ser protegida.

3) El tribunal arbitral podrá adoptar disposiciones logísticas para facilitar el acceso del público a las audiencias (incluso, según proceda, organizando la asistencia mediante enlaces de vídeo u otros medios que estime convenientes) y podrá, tras celebrar consultas con las partes litigantes, decidir que toda la audiencia o parte de ella se celebre en privado cuando sea necesario por motivos logísticos, por ejemplo, cuando debido a las circunstancias, no pueda adoptarse ninguna disposición logística viable para permitir el acceso del público a las audiencias.”

“Artículo 7

Información confidencial o protegida

1) La información confidencial o protegida, como se define en el párrafo 2 y se determina de conformidad con las disposiciones a que se hace referencia en los párrafos 4 y 5, no se pondrá a disposición del público ni de las partes en el tratado que no sean litigantes con arreglo a los artículos 2 a 6.

2) Se entiende por información confidencial o protegida: a) La información comercial confidencial; b) La información que no debe ponerse a disposición del público, con arreglo al tratado; c) La información que no debe ponerse a disposición del público, en el caso de la información del demandado, con arreglo a la legislación del demandado, y en el caso de información de otro

tipo, con arreglo a cualquier ley o reglamento que el tribunal arbitral determine que es aplicable a la divulgación de esa clase de información; o d) La información cuya divulgación impediría la aplicación de la ley.

3) Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento obligará al demandado a facilitar al público información cuya divulgación estime que sería contraria a sus intereses de seguridad esenciales.

4) El tribunal arbitral, en consulta con las partes litigantes, tomará disposiciones para impedir que la información confidencial o protegida sea puesta a disposición del público o de las partes en el tratado no litigantes, incluso estableciendo, según proceda a) plazos para que una parte litigante, una parte en el tratado no litigante o un tercero notifique que desea proteger dicha información en un documento, b) procedimientos para seleccionar y suprimir rápidamente de los documentos en cuestión la información confidencial o protegida, y c) procedimientos para celebrar audiencias en privado, en la medida en que ello se prevea en el artículo 6, párrafo 2. El tribunal arbitral decidirá, previa consulta con las partes litigantes, si determinada información es confidencial o protegida.

5) Si el tribunal arbitral determina que no debe suprimirse información de un documento, o que no debe impedirse que un documento se haga público, las partes litigantes, las partes en el tratado no litigantes o los terceros que voluntariamente hayan incorporado el documento al expediente de las actuaciones arbitrales podrán retirarlo en su totalidad o en parte de dicho expediente.

Integridad del proceso arbitral

6) No se pondrá información a disposición del público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 a 6 cuando esa información, si se pusiera a disposición del público, pudiera comprometer la integridad del proceso arbitral según se haya determinado de conformidad con el párrafo 7.

7) El tribunal arbitral podrá, por iniciativa propia o a instancia de una parte litigante, previa consulta con las partes litigantes cuando sea viable, adoptar las medidas pertinentes para impedir o retrasar la publicación de información cuando dicha publicación pudiera comprometer la integridad del proceso arbitral porque a) pudiera obstaculizar la reunión o la presentación de pruebas, o b) pudiera dar lugar a la intimidación de testigos, abogados representantes de partes litigantes, o miembros del tribunal arbitral, o c) en circunstancias excepcionales comparables.”

76. Todas las delegaciones apoyaron la propuesta de transacción revisada, con excepción de dos, que indicaron que podían recomendar positivamente el texto a sus gobiernos, pero necesitaban más tiempo para examinar esa propuesta.

77. Tras un debate, esas delegaciones aceptaron formalmente la propuesta de transacción revisada que figura en el párrafo 75 del presente documento, y una delegación expresó preocupaciones respecto del artículo 6 1) en relación con las audiencias públicas.

78. El Grupo de Trabajo expresó su apoyo formal y unánime a la propuesta de transacción revisada.

Modificación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI

79. El Grupo de Trabajo convino en que, habida cuenta de la solución lograda que se hace constar en el párrafo 75, sería preciso modificar el artículo 1 4) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI a fin de articular una vinculación con el reglamento sobre la transparencia de conformidad con el texto que figura en el párrafo 15 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176, y que esa modificación daría lugar a una nueva versión de 2013 o 2014 del Reglamento.

80. El Grupo de Trabajo convino en que el texto que figuraba en el párrafo 15 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176, con la adición de las palabras entre corchetes “[como apéndice]” después de las palabras “incluye el Reglamento sobre la Transparencia de la CNUDMI”, se presentaría a la Comisión a ese respecto.

C. Establecimiento de un registro de la información publicada**1. Institución(es) que desempeñará(n) la función de registro**

81. El Grupo de Trabajo examinó el artículo 8 contenido en el párrafo 9 del documento A/CN.9/WG.II/WP.176/Add.1, que se refería al archivo de la información publicada, en el cual figuraban dos variantes relativas a la posible administración institucional de un registro -por un lado, un registro único que desempeñaría todas las funciones (variante 1); y por el otro, un sistema mediante el cual diversas instituciones arbitrales mantendrían su propio sistema de registro (variante 2).

82. El Grupo de Trabajo también tuvo a su disposición una nota de la Secretaría (A/CN.9/WG.II/WP.177) de conformidad con el mandato encomendado por el Grupo de Trabajo a la Secretaría de que estableciera enlaces con instituciones arbitrales a fin de evaluar mejor el costo y otras repercusiones del establecimiento de un registro en el marco del proyecto de reglamento sobre la transparencia (A/CN.9/760, párrs. 122 y 123).

83. El Grupo de Trabajo observó que las instituciones arbitrales mostraban una clara preferencia por que una sola institución asumiera la función de registro (variante 1 del proyecto de artículo 8), por varios motivos (A/CN.9/WG.II/WP.177, párrs. 6 a 11). Tras deliberar, el Grupo de Trabajo acordó que la variante 1, relativa a un registro único, era su preferida, y procedió a examinar qué institución debería desempeñar esa función.

84. El Grupo de Trabajo expresó la opinión unánime de que la CNUDMI sería la institución que mejor podría hacer de registro conforme al reglamento sobre la transparencia.

85. El Grupo de Trabajo también tomó nota de que otras dos instituciones, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, estaban dispuestas a asumir la función de registro único conforme al reglamento sobre la transparencia en caso de que la CNUDMI no estuviera en condiciones de desempeñar esa función.

2. Documentos en papel

86. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo acordó, teniendo en cuenta las cuestiones planteadas en el párrafo 15 del documento A/CN.9/WG.II/WP.177, que el registro publicara únicamente documentos electrónicos. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo convino en suprimir el texto del proyecto de artículo 8 que figuraba entre corchetes.

3. Directrices

87. El Grupo de Trabajo acordó que se debía redactar un documento en el que se establecieran directrices para el funcionamiento del registro y que correspondería a la institución que asumiera en definitiva las funciones de registro la preparación de tales directrices.

4. Exención de responsabilidad

88. El Grupo de Trabajo examinó si debía añadirse al reglamento una cláusula de exención de responsabilidad, con respecto tanto al tribunal arbitral, por conducto del cual se enviarían los documentos al registro conforme al artículo 3, como al propio registro. También se planteó la cuestión de cómo proceder ante las reclamaciones de responsabilidad presentadas por terceros (por ejemplo, en casos de violación de la privacidad de los datos). El Grupo de Trabajo convino en que el registro debía gozar de la más amplia inmunidad posible. Se acordó que la secretaría de la CNUDMI, el Tribunal Permanente de Arbitraje y el CIADI examinaran si, en relación con sus respectivas instituciones, habría que incluir en el reglamento una cláusula de exención de responsabilidad, teniendo en cuenta que podrían gozar de determinadas inmunidades en virtud de su condición de organizaciones internacionales.

D. Examen de cuestiones de redacción pendientes relativas al proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado

89. El Grupo de Trabajo convino en examinar las cuestiones de redacción pendientes relativas al reglamento sobre la transparencia. Se aclaró que el principio rector al examinar esas sugerencias había de ser garantizar que el reglamento funcionara debidamente, pero sin alterar en modo alguno el fondo de las disposiciones ya acordadas.

1. Artículo 2 - Publicación de información tras el inicio del procedimiento arbitral

90. A fin de aclarar que la notificación de arbitraje se había enviado al demandado, o había sido recibida por él, antes de publicar la información con arreglo a lo establecido en el artículo 2, el Grupo de Trabajo convino en que se modificase la segunda oración del artículo 2 para que rezara así: “Tras haber recibido la notificación del arbitraje del demandado, o tras haber recibido la notificación del arbitraje y la constancia de su transmisión al demandado, el archivo procederá sin demora a poner a disposición del público la información relativa al nombre de las partes litigantes, el sector económico afectado y el tratado en virtud del cual se formula la demanda”.

2. Artículo 3 - Publicación de documentos

Consideraciones generales

91. El Grupo de Trabajo examinó la forma en que el registro atendería las solicitudes de documentos una vez que el tribunal arbitral hubiera cumplido su función y su mandato hubiera concluido. Se aclaró que las solicitudes de documentos deberían formularse antes de que terminara el arbitraje ya que, en todo caso, solo el tribunal arbitral podía comunicar al registro los documentos que este habría de publicar. Se sugirió que se instase a las partes litigantes a establecer un arreglo para atender las solicitudes de documentos una vez que el tribunal arbitral hubiera cumplido su función.

Párrafos 1), 2) y 3)

92. En lo que respecta a la redacción, el Grupo de Trabajo convino en eliminar la frase “que deben solicitarse por separado con arreglo al párrafo 3”, que figuraba en el proyecto de artículo 3, párrafos 1) y 2). Además, el Grupo de Trabajo convino en añadir en la primera oración del párrafo 3) las palabras “las pruebas y” antes de las palabras “cualquier otro documento”.

Párrafo 2)

93. El Grupo de Trabajo siguió examinando si el párrafo 2) podría crear cierta ambigüedad en relación con una solicitud de los informes de los peritos y las declaraciones de los testigos formulada después de que el tribunal hubiera cumplido sus funciones (A/CN.9/WG.II/WP.177, párr. 23). Se acordó añadir las palabras “al tribunal arbitral” al final del párrafo 2), con el fin de aclarar (como ya se ha expuesto en el párrafo 91) que las solicitudes se deberán formular mientras el tribunal esté en activo.

Párrafo 5)

94. El Grupo de Trabajo tomó nota de la inquietud expresada en el sentido de que la frase “todos los gastos administrativos”, del párrafo 5), podría resultar ambigua ya que podría sugerir, erróneamente, que un tercero tal vez tuviera que sufragar los gastos administrativos relativos a la publicación, por ejemplo, los relacionados con la carga al sitio web del registro. El Grupo de Trabajo solicitó que la Secretaría modificara el texto en consecuencia.

V. Otros asuntos

95. El Grupo de Trabajo recordó que la Comisión había encomendado a la Secretaría la preparación de una guía sobre la Convención de Nueva York para promover una interpretación y aplicación más uniformes de dicha Convención. La Secretaría llevaba a cabo el proyecto en estrecha cooperación con los profesores G. Bermann y E. Gaillard. El Sr. Gaillard, con su equipo de investigación, junto con el Sr. Bermann y su equipo, habían establecido con el apoyo de la Secretaría un sitio web (www.newyorkconvention1958.org) cuyo objeto era poner a disposición del público la información recopilada en la preparación de la guía sobre la Convención

de Nueva York. El objetivo del sitio web era dar detalles de la interpretación judicial de la Convención por los Estados parte.

96. Se informó al Grupo de Trabajo de que el sitio web newyorkconvention1958.org se había mejorado y racionalizado para que la nueva versión fuera más completa y fácil de usar y sirviera de instrumento de investigación e información para legisladores, jueces, profesionales, partes y docentes. Se había mejorado el interfaz para facilitar búsquedas rápidas y avanzadas, que podrían realizarse pulsando en iconos, casillas o sugerencias de términos de búsqueda. El sitio web tenía capacidad para manipular ecuaciones de búsqueda complejas y rastrear los resultados de búsquedas de múltiples pasos. Como parte de la actualización más reciente del sitio web, los usuarios podían acceder a una base de datos más amplia y que seguía ampliándose. Hasta la fecha, el sitio web newyorkconvention1958.org contenía resúmenes de 782 casos sobre la aplicación de la Convención de Nueva York en 18 ordenamientos jurídicos y ponía a disposición del público más de 900 decisiones en el idioma original de su publicación y 90 traducciones al inglés.

97. Se añadiría jurisprudencia y resúmenes de otros ordenamientos jurídicos continuamente. A ese respecto, se invitó a los delegados a que aportaran jurisprudencia de sus países a través del sitio web.

98. El Grupo de Trabajo expresó su aprecio por el establecimiento y la actualización del sitio web. En especial, se expresó aprecio a la Sra. Yas Banifatemi, que había coordinado la labor realizada en el marco del proyecto.

**F. Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales:
preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los
arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco
de un tratado, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje
y Conciliación en su 58º período de sesiones**

(A/CN.9/WG.II/WP.176 y Add.1)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-5
II. Proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	6-47
A. Observaciones generales	6
B. Contenido del proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado de inversiones	7-47
Artículo 1. Ámbito de aplicación	7-21
Artículo 2. Publicación de información al inicio de las actuaciones arbitrales	22-24
Artículo 3. Publicación de documentos	25-35
Artículo 4. Presentaciones a cargo de terceros	36-37
Artículo 5. Presentaciones por partes en el tratado que no sean litigantes . . .	38-43
Artículo 6. Audiencias	44-47

I. Introducción

1. En su 43º período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010), la Comisión recordó, respecto de la labor futura en materia de solución de controversias comerciales, la decisión adoptada en su 41º período de sesiones (Nueva York, 16 de junio a 3 de julio de 2008)¹ de que, una vez concluida la revisión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, se abordara, con carácter prioritario, el tema de la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado. La Comisión encomendó a su Grupo de Trabajo II la tarea de preparar una norma jurídica sobre ese tema².

2. En su 44º período de sesiones (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011), la Comisión reiteró el compromiso que había expresado en su 41º período de sesiones

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, Sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr. 1), párr. 314.*

² *Ibid., Sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), párr. 190.*

respecto de la importancia de asegurar la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado. Se confirmó que la cuestión de la aplicabilidad de la norma jurídica sobre la transparencia a los tratados de inversiones vigentes formaba parte del mandato del Grupo de Trabajo y era una cuestión que revestía un gran interés práctico, habida cuenta del gran número de tratados ya concertados³.

3. En su 45º período de sesiones (25 de junio a 6 de julio de 2012), la Comisión reafirmó la importancia de garantizar la transparencia de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, reconocida en sus períodos de sesiones 41º y 44º, celebrados respectivamente en 2008 y 2011⁴, e instó al Grupo de Trabajo a que prosiguiera y concluyera su labor relativa a las normas sobre transparencia, para someterlas al examen de la Comisión, de preferencia en su próximo período de sesiones⁵.

4. En sus períodos de sesiones 53º (Viena, 4 a 8 de octubre de 2010) y 54º (Nueva York, 7 a 11 de febrero de 2011), el Grupo de Trabajo examinó las cuestiones de la forma, la aplicabilidad y el contenido de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado⁶. En su 55º período de sesiones (Viena, 3 a 7 de octubre de 2011), el Grupo de Trabajo concluyó la primera lectura del proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (que figura en el documento A/CN.9/WG.II/WP.166 y su adición)⁷. En sus períodos de sesiones 56º (Nueva York, 6 a 10 de febrero de 2012) y 57º (Viena, 1 a 5 de octubre de 2012), el Grupo de Trabajo inició la segunda lectura del proyecto de reglamento sobre la transparencia (que figura en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169 y su adición)⁸.

5. De conformidad con las decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo en su 57º período de sesiones (A/CN.9/760, párr. 12), la parte II de la presente nota contiene un proyecto revisado del Reglamento sobre la Transparencia (los artículos 1 a 6 se tratan en la presente nota y en su adición se tratan los artículos 7 y 8). La cuestión de los instrumentos que pueden prepararse relativos a la aplicación del reglamento sobre la transparencia a la solución de las controversias dimanadas de tratados de inversiones concertados antes de la fecha de aprobación del Reglamento sobre la Transparencia se aborda en la parte III (de la adición a la presente nota), así como en el documento A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1, parte III.

³ *Ibid.*, Sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 200.

⁴ *Ibid.*, Sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 y corrección (A/63/17 y Corr.1), párr. 314; *Ibid.*, Sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 200.

⁵ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párrs. 65 a 69.

⁶ Informes del Grupo de Trabajo sobre la labor realizada en sus períodos de sesiones 53º (A/CN.9/712) y 54º (A/CN.9/717).

⁷ Informe del Grupo de Trabajo sobre la labor realizada en su 55º período de sesiones (A/CN.9/736).

⁸ Informe del Grupo de Trabajo sobre la labor realizada en sus períodos de sesiones 56º (A/CN.9/741) y 57º (A/CN.9/760).

II. Proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado

A. Observaciones generales

Lista de cuestiones pendientes para su examen por el Grupo de Trabajo

6. En su 57º período de sesiones, el Grupo de Trabajo tomó nota de las cuestiones que habían quedado pendientes para su examen como parte de la tercera lectura del proyecto de reglamento sobre la transparencia, como sigue: el párrafo 1 del artículo 1 sobre el ámbito de aplicación (véanse *infra* los párrafos 8 a 16); el párrafo 1 del artículo 5, sobre si se deberían utilizar las palabras “podrá permitir” o “permitirá” en relación con la autorización por el tribunal arbitral de presentaciones sobre la interpretación de los tratados por una parte en el tratado no litigante (véase *infra* el párrafo 40); el párrafo 1 del artículo 6, en relación con la cuestión de las audiencias públicas y si una parte litigante debería tener el derecho unilateral a pedir que las audiencias fueran en privado (véase *infra* el párrafo 45); el apartado c) del párrafo 2 del artículo 7 y un proyecto de propuesta de dos nuevos párrafos, con la numeración provisional de 2) d) y 2) *bis*, en relación con la definición de información confidencial o protegida y una disposición sobre la facultad del demandado de impedir la revelación de cierta información, respectivamente (véase el documento A/CN.9/WG.II/WP.176/Add.1, párrs. 4 a 6); y el artículo 8 sobre la organización de un archivo de la información puesta a disposición del público (véase el documento A/CN.9/WG.II/WP.176/Add.1, párrs. 10 y 11).

B. Contenido del proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado

Artículo 1. Ámbito de aplicación

7. Proyecto de artículo 1 - Ámbito de aplicación.

Párrafo 1) - Aplicabilidad de la norma jurídica sobre la transparencia

Opción 1 (véase el documento A/CN.9/WG.II/WP.172, párrs. 6 a 18)

“1. El Reglamento sobre la Transparencia será aplicable a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados de conformidad con un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas (“el tratado”) cuando las partes en el tratado [o todas las partes en el arbitraje (las “partes litigantes”)] hayan convenido en su aplicación. En un tratado celebrado después del [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia], se presumirá que toda remisión que se haga en el tratado al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI incluye el Reglamento sobre la Transparencia, a menos que las partes en el tratado hayan convenido lo contrario, por ejemplo, remitiendo a una determinada versión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI [que no haga referencia al Reglamento sobre la Transparencia].”*

Opción 2 (véase documento A/CN.9/760, párr. 132)

“1. El Reglamento sobre la Transparencia se aplicará a los arbitrajes entre inversionistas y Estados enablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas (“el tratado”) celebrado después de [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia], a menos que las partes en el tratado hayan acordado otra cosa.

2. Con respecto a i) los arbitrajes entre inversionistas y Estados enablados, en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con un tratado celebrado antes de [fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia] y ii) los arbitrajes entre inversionistas y Estados enablados con arreglo a otros reglamentos de arbitraje o con carácter especial, el Reglamento sobre la Transparencia [solamente] se aplicará [si] [a reserva de que]:

a) la partes litigantes [convienen] en su aplicación respecto de ese arbitraje; o,

b) las partes en el tratado, o en el caso de un tratado multilateral, el Estado del que el inversionista sea ciudadano, y el que el inversionista y el demandado hayan convenido para la aplicación del presente Reglamento [en un instrumento adoptado] [después de] [fecha de la entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia].”

Opción 3 (véase el documento A/CN.9/WG.II/WP.174)

“1. Si un tratado concertado antes de la [fecha de aprobación/fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia] remite al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, esa remisión denotará la versión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI que lleve incorporado el Reglamento sobre la Transparencia siempre que el tratado, interpretado en conformidad con el derecho internacional, refleje el acuerdo de las partes en el mismo en aplicar esa versión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Las partes en el tratado podrán convenir también, tras la [fecha de aprobación/fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia], en aplicar el Reglamento sobre la Transparencia en el marco de un tratado concertado antes de esa fecha.”

Párrafo 2) - Aplicación del Reglamento sobre la Transparencia por las partes litigantes

“2. En todo arbitraje en que sea aplicable el Reglamento sobre la Transparencia de conformidad con un tratado o con un acuerdo concertado por las Partes en ese tratado,

a) las [partes litigantes] [las partes en el arbitraje (las “partes litigantes”)] no podrán apartarse de ese reglamento mediante acuerdo o del modo que fuere, a menos que el tratado se lo permita;

b) el tribunal arbitral, al margen de las facultades discrecionales que le confieren algunas disposiciones del presente Reglamento sobre la Transparencia, estará facultado para adaptar los requisitos de cualquier disposición concreta del presente Reglamento a las circunstancias del caso si ello resulta necesario para lograr en la práctica el objetivo de la transparencia del Reglamento.”

Párrafo 3) - Relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el reglamento de arbitraje aplicable

“3. Siempre que el Reglamento sobre la Transparencia sea aplicable, complementará cualquier otro reglamento de arbitraje aplicable. Cuando exista un conflicto entre el Reglamento sobre la Transparencia y las normas de arbitraje aplicables, prevalecerá el Reglamento sobre la Transparencia.”

Párrafo 4) - Relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el derecho aplicable

“4. Cuando una norma de este Reglamento esté en conflicto con una disposición del derecho aplicable al arbitraje que las partes no puedan derogar, prevalecerá esa disposición.”

Párrafo 5) - Discrecionalidad del tribunal arbitral

“5. Cuando el Reglamento establezca que el tribunal arbitral tendrá facultades discrecionales, en el ejercicio de tales facultades el tribunal arbitral tendrá en cuenta: a) el interés público en la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado de inversiones y en el procedimiento arbitral en particular, y b) el interés de las partes litigantes en que la controversia se resuelva de manera justa y eficaz.”

Nota a pie de página del párrafo 1 del artículo 1:

“ A los fines del Reglamento sobre la Transparencia, por “tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas”, se entenderá en sentido amplio todo acuerdo concertado entre Estados u organizaciones de integración regional, incluidos asociaciones de libre comercio, acuerdos de integración económica, acuerdos marco de comercio o inversiones o de cooperación y tratados bilaterales y multilaterales de inversiones, siempre que estos contengan disposiciones sobre la protección de las inversiones o los inversionistas y el derecho de los inversionistas a recurrir al arbitraje contra las partes en el tratado.”*

Observaciones

Párrafo 1) - Aplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia

8. En su 56° período de sesiones, el Grupo de Trabajo encomendó a la secretaría la preparación de una versión revisada del párrafo 1 del artículo 1 (A/CN.9/741, párrs. 54 y 57). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó dos opciones con relación a la aplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia. Según la primera opción, la solución de exclusión, el Reglamento sobre la

Transparencia se incorporaría al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010) y, en consecuencia, se aplicaría en el marco de los tratados de inversiones que previeran procedimientos regidos por el Reglamento de Arbitraje, a menos que el tratado dispusiera la inaplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia (A/CN.9/741, párr. 14). En lo que respecta a esta solución, se debatió sobre si el Reglamento sobre la Transparencia también se aplicaría a los arbitrajes derivados de los tratados ya existentes. Se dijo que la aplicación del reglamento a los tratados existentes podría resultar de una “interpretación dinámica” de un tratado de inversiones, en el sentido de que una referencia a dicho tratado en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI podría interpretarse que incorporaba el Reglamento sobre la Transparencia (A/CN.9/741, párrs. 20 y 42). En virtud de la segunda opción, la solución de adhesión, el Reglamento sobre la Transparencia solo sería aplicable cuando las Altas Partes Contratantes (denominadas “Partes”) en un tratado de inversiones consintieran expresamente en su aplicación (A/CN.9/741, párr. 14).

- Opción 1

9. En ese período de sesiones, las posiciones expresadas diferían en cuanto a i) si era preferible la solución de adhesión o la de exclusión; y ii) si habría que dejar abierta la posibilidad de una interpretación dinámica de los tratados de inversiones ya existentes (A/CN.9/741, párr. 55). De conformidad con las instrucciones del Grupo de Trabajo para reformular el proyecto de párrafo 1 del artículo 1 teniendo en cuenta las deliberaciones celebradas en su 56° período de sesiones (A/CN.9/741, párrs. 54 y 57), la opción 1, reproducida en el párrafo 7 *supra*, fue propuesta en el párrafo 6 del documento A/CN.9/WG.II/WP.172. La primera frase del proyecto de párrafo 1 establece el principio general de derecho internacional público que afirma que las partes únicamente estarán sujetas a un conjunto externo de normas si así lo decidieran. La segunda frase del párrafo 1 se refiere a los tratados celebrados con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia. En ella se establece una presunción a favor de la aplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia.

10. Se pidió a las delegaciones que tenían problemas para aceptar el enfoque descrito en el párrafo 9 que transmitieran a la secretaría sus propuestas de redacción al respecto a fin de someterlas al examen del Grupo de Trabajo (A/CN.9/741, párr. 59). Las opciones 2 y 3 corresponden a las propuestas formuladas por las delegaciones.

- Opción 2

11. En el 57° período de sesiones del Grupo de Trabajo se propuso la opción 2 para ser examinada más a fondo. En el párrafo 1) se establece el principio de que para los tratados celebrados después de la fecha de adopción del Reglamento sobre la Transparencia, el Reglamento se aplicará cuando se haya iniciado el litigio en el marco del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI a menos que las partes en el tratado hayan acordado otra cosa. El párrafo 2) establece el principio de que para los tratados concluidos antes de la fecha de adopción del Reglamento sobre la Transparencia este se aplicará a un litigio iniciado de conformidad con cualquier reglamento de arbitraje en que a) las partes litigantes acuerden su aplicación respecto de ese arbitraje; o b) las partes en el tratado hayan acordado que así fuera

después de la fecha de adopción/entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia. Como parte de la opción 2, se formuló la propuesta de modificar el artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 (véase *infra*, párrafo 15).

- Opción 3

12. La opción 3 también tiene por objeto establecer principios de aplicación del Reglamento sobre la Transparencia para los tratados de inversiones concertados antes de la fecha de adopción del Reglamento sobre la Transparencia. Esta propuesta (que también se reproduce con observaciones en el documento A/CN.9/WG.II/WP.174) se formuló sobre la base que no se estableciera ninguna norma o presunción en el Reglamento sobre la Transparencia respecto de su aplicación en virtud de los tratados existentes, sino que, por el contrario, debían prevalecer las normas internacionalmente aceptadas de interpretación de los tratados (A/CN.9/760, párr. 140).

- *El Reglamento sobre la Transparencia como reglamento independiente o apéndice*

13. En su 56º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la secretaría que le proporcionara un análisis de las repercusiones que tendría la presentación del Reglamento sobre la Transparencia en forma de apéndice al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 o como texto independiente. Si el Reglamento sobre la Transparencia se convirtiera en un apéndice de dicho Reglamento de Arbitraje, habría tres reglamentos de arbitraje de la CNUDMI: el Reglamento de Arbitraje de 1976, el Reglamento de arbitraje de 2010 y el Reglamento de Arbitraje de 2013 (véase el documento A/CN.9/WG.II/WP.172, párrs. 11 a 16).

14. En el 56º período de sesiones del Grupo de Trabajo, las delegaciones expresaron su preocupación acerca de la dificultad de excluir la posibilidad de una interpretación dinámica si el Reglamento sobre la Transparencia se presentara como apéndice al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (A/CN.9/741, párr. 57). Si el Reglamento sobre la Transparencia adoptase la forma de un reglamento independiente, sería más limitada la posibilidad de una interpretación dinámica.

15. En el 57º período de sesiones del Grupo de Trabajo, se formuló la propuesta de articular la vinculación entre el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y el Reglamento sobre la Transparencia, sin hacer formalmente del Reglamento sobre la Transparencia parte, o un anexo, del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010. Esta propuesta se formuló conjuntamente con la opción 2 (véase *supra* el párrafo 11) (A/CN.9/760, párr. 133). A ese respecto, se propuso modificar el artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de 2010 como sigue: “4. *En relación con los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados con arreglo a un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas, el presente Reglamento de Arbitraje incluye el Reglamento sobre la Transparencia de la CNUDMI [con las modificaciones que se introduzcan de tiempo en tiempo], a reserva de lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia.*” El Grupo de Trabajo tal vez desee tener presente que, si el Reglamento sobre la Transparencia fuera un texto independiente, podría no ser necesario modificar el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010. El Reglamento sobre la Transparencia se aplicaría conjuntamente con el Reglamento de

Arbitraje de la CNUDMI ya que se aplicarían conjuntamente con cualquier otro reglamento de arbitraje.

- Fecha de aprobación/fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia

16. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si la fecha de entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia debería ser la fecha de su aprobación por la Comisión, o una fecha ulterior.

Párrafo 2) – Aplicación del Reglamento sobre la Transparencia por las partes litigantes

17. El párrafo 2) refleja las modificaciones consideradas aceptables por el Grupo de Trabajo en su 56º período de sesiones (A/CN.9/741, párrs. 74, 78 y 81). Establece el principio según el cual las partes litigantes no podrán retraerse del cumplimiento del Reglamento sobre la Transparencia, salvo que así lo establezca el tratado. La razón es que no sería apropiado que las partes litigantes revocaran una decisión adoptada al respecto por las partes en el tratado de inversiones y en particular porque el Reglamento tiene por objeto beneficiar no solo al inversionista y al Estado anfitrión, sino también a la población en su conjunto (A/CN.9/741, párr. 61). De conformidad con la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo en su 56º período de sesiones, el párrafo 2 prevé, además, la posibilidad de que el tribunal arbitral pueda adaptar el Reglamento sobre la Transparencia (A/CN.9/741, párrs. 73, 74, 78 y 81). En lo que respecta a la redacción, si se mantuviera la referencia a las partes litigantes en el párrafo 1, se suprimiría en el párrafo 2) a) la definición de partes litigantes.

Párrafo 3) – Relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el reglamento de arbitraje aplicable

18. En su 56º período de sesiones del Grupo de Trabajo, la gran mayoría de las delegaciones era partidaria de incluir en el Reglamento sobre la Transparencia una disposición sobre la relación entre ese Reglamento y el reglamento de arbitraje aplicable (A/CN.9/741, párr. 97).

Párrafo 4) – Relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el derecho aplicable

19. En su 56º período de sesiones, el Grupo de Trabajo dio instrucciones a la secretaría para que complementase la disposición relativa a la relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el reglamento de arbitraje aplicable, mediante una disposición sobre la relación entre el Reglamento sobre la Transparencia y el derecho aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 3) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 (A/CN.9/741, párr. 97). El Grupo de Trabajo quizás desee examinar el artículo 1 4) contenido en el párrafo 7 *supra* que refleja rigurosamente el enunciado del artículo 1 3) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010. El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que, en función de la legislación interna aplicable, las partes litigantes pueden entonces retraerse del cumplimiento del Reglamento sobre la Transparencia (véase asimismo el documento A/CN.9/WG.II/WP.176/Add.1, párrs. 4 a 6).

Párrafo 5) – Discrecionalidad del tribunal arbitral

20. En su 56º período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del párrafo 5 (A/CN.9/741, párr. 85).

Nota a pie de página del párrafo 1 del artículo 1

21. La nota a pie de página del artículo 1 1), que da una definición de la expresión “un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas” refleja las propuestas de redacción formuladas en el 56º período de sesiones del Grupo de Trabajo. La nota tiene por objeto aclarar que la idea de que el Reglamento sobre la Transparencia sería aplicable a los tratados de inversiones debería interpretarse en un sentido amplio. El Grupo de Trabajo aprobó la nota, con sujeción a la supresión del término “intergubernamentales” después de las palabras “u organizaciones” y a que se aludiera a la “protección de las inversiones y los inversionistas” de forma coherente (A/CN.9/741, párrs. 101 y 102).

Artículo 2. Publicación de información en el inicio de las actuaciones arbitrales

22. Proyecto de artículo 2 - Publicación de información tras el inicio de las actuaciones arbitrales.

“Una vez que el demandado haya recibido la notificación del arbitraje, cada una de las partes litigantes comunicarán sin demora al archivo mencionado en el artículo 8 una copia de la notificación del arbitraje. Tras la recepción de la notificación del arbitraje de cualquiera de las partes litigantes, el archivo procederá sin demora a poner a disposición del público la información relativa al nombre de las partes litigantes, el sector económico afectado y el tratado en virtud del cual se formula la reclamación.”

Observaciones

23. En su 56º período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó la versión del artículo 2 por la que la publicación de la notificación del arbitraje (y de su contestación) se regularía en virtud del artículo 3 una vez constituido el tribunal arbitral (A/CN.9/741, párr. 109). El artículo 2 contiene las modificaciones de redacción acordadas por el Grupo de Trabajo (A/CN.9/741, párr. 109), con el fin de aclarar que todas las partes litigantes estarán obligadas a enviar la notificación del arbitraje al archivo. El archivo a su vez, deberá publicar la información una vez que reciba la notificación del arbitraje de cualquiera de las partes litigantes.

24. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar: i) cómo tratar las situaciones en que el demandante envíe la notificación de arbitraje al archivo antes de que comiencen las actuaciones arbitrales, es decir, antes de que el demandado haya recibido dicha notificación (A/CN.9/741, párr. 107); ii) si las palabras iniciales “una vez que el demandado haya recibido la notificación del arbitraje” resuelven satisfactoriamente la cuestión; iii) las dificultades que esa situación puede suponer para el archivo en lo que respecta al cumplimiento de sus funciones administrativas.

Artículo 3. Publicación de documentos

25. Proyecto de artículo 3 – Publicación de documentos.

“1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 7, los documentos siguientes se darán a conocer al público: la notificación del arbitraje; la respuesta a la notificación del arbitraje; el escrito de demanda, el escrito de contestación y toda otra declaración o presentación por escrito de cualquiera de las partes litigantes; una lista de todas las pruebas correspondientes a dichos documentos y a las declaraciones de los testigos y los informes de los peritos, si esa lista ha sido preparada para las actuaciones pero no las pruebas en sí, que deben solicitarse por separado con arreglo al párrafo 3; toda presentación por escrito hecha por partes en el tratado que no sean litigantes y por terceros; las transcripciones de las audiencias, cuando se dispusiera de ellas; y las providencias, decisiones y dictámenes del tribunal arbitral.

2. A reserva de lo dispuesto en el artículo 7, las declaraciones de los testigos y los informes de los peritos, excluidas las pruebas correspondientes que deben solicitarse por separado con arreglo al párrafo 3, se pondrán a disposición del público, mediante petición de cualquier persona.

3. A reserva de lo dispuesto en el artículo 7, el tribunal arbitral podrá decidir, de oficio o a solicitud de cualquier persona, previa consulta a las partes litigantes, si cualquier documento que emita o reciba el tribunal arbitral no incluido en los párrafos 1 o 2 supra, se publicará y de qué forma. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que se pongan esos documentos a disposición del público en un lugar determinado.

4. Los documentos puestos a disposición del público con arreglo a lo establecido en los párrafos 1 y 2 serán comunicados por el tribunal arbitral al archivo mencionado en el artículo 8 lo antes posible, de conformidad con cualquier disposición o plazo para la protección de la confidencialidad o información protegida establecidos en el artículo 7. Los documentos que se pongan a disposición con arreglo a lo establecido en el párrafo 3 podrán ser comunicados por el tribunal arbitral al archivo mencionado en el artículo 8 a medida que se disponga de ellos y, cuando proceda, en su forma expurgada de conformidad con el artículo 7. El archivo hará públicos oportunamente todos los documentos disponibles en la forma y el idioma en que los reciba.

5. Una persona que no sea una parte litigante, que tenga acceso a los documentos con arreglo a lo establecido en los párrafos 2 o 3, sufragará todos los gastos administrativos de ese acceso (como los de fotocopiado o envío).”

Observaciones

26. El artículo 3 refleja una propuesta formulada en el 55º período de sesiones del Grupo de Trabajo de que en las disposiciones sobre publicación de documentos se enunciara lo siguiente: i) una lista de los documentos puestos a disposición del público; ii) las facultades discrecionales del tribunal arbitral de ordenar que se hagan públicos documentos adicionales; y iii) la oportunidad a terceros de solicitar acceso a los documentos adicionales (A/CN.9/736, párrs. 54 a 66). Se consideró que una disposición de este tipo establecería un equilibrio adecuado entre los documentos puestos a disposición del público y el ejercicio por el tribunal arbitral

de sus facultades discrecionales en la tramitación del proceso (A/CN.9/736, párrs. 58 y 65).

Párrafo 1) – Lista de documentos

- lista de pruebas

27. Se han incluido las palabras “si esa lista ha sido preparada para las actuaciones, pero no las pruebas en sí, que deben solicitarse por separado con arreglo al párrafo 3” para reflejar las decisiones del Grupo de Trabajo en su 57º período de sesiones en el sentido de que: i) en los casos en que ya existiera una lista de pruebas, habría la obligación de darla a conocer conforme a lo dispuesto en el párrafo 1), pero si no se hubiese presentado una lista de pruebas en el curso del procedimiento, no se exigiría crearla a efectos de darla a conocer de conformidad con el artículo 3 (A/CN.9/760, párr. 16); y ii) las pruebas mismas no se regirían por el párrafo 1) sino que quedarían sujetas a divulgación con carácter discrecional en virtud de otras disposiciones del artículo 3 (A/CN.9/760, párr. 15).

- informes de los peritos y declaraciones de los testigos

28. En el párrafo 1) se ha suprimido de la lista la referencia a declaraciones de los testigos e informes de los peritos de conformidad con la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo en su 57º período de sesiones de que esos documentos se excluyeran del ámbito del párrafo 1) y se trataran por separado (A/CN.9/760, párrs. 20 y 22) (véase *infra* párr. 31).

- transcripciones

29. En su 57º período de sesiones, el Grupo de Trabajo recordó sus deliberaciones anteriores y el acuerdo de incluir las transcripciones en el artículo 3, párrafo 1, en la inteligencia de que la información confidencial que allí constase podría expurgarse, y, por consiguiente, que las transcripciones deberían tratarse de la misma manera que los demás documentos enumerados en el párrafo 1). Las palabras “cuando se dispusiera de ellas” tienen por objeto aclarar que el artículo 3 no impone la obligación de presentar transcripciones cuando no se hubieran hecho en el curso del procedimiento (A/CN.9/760, párrs. 23 y 24).

- laudos arbitrales

30. En virtud de una decisión del Grupo de Trabajo adoptada en su 57º período de sesiones, los laudos arbitrales se incluyen ahora en la lista de documentos que han de hacerse públicos con arreglo al párrafo 1 del artículo 3, y de esa manera queda obsoleto el artículo 4 del proyecto de reglamento anterior (contenido en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169, párr. 33) (A/CN.9/760, párr. 38). Por lo tanto, ese artículo ha sido suprimido y las disposiciones del proyecto de reglamento se han numerado nuevamente en consecuencia.

Párrafo 2) – Informes de los peritos y declaraciones de los testigos

31. El párrafo 2) es un nuevo párrafo en el que aparece reflejada la decisión del Grupo de Trabajo adoptada en su 57º período de sesiones de que los informes de los peritos y las declaraciones de los testigos se excluyan del ámbito del párrafo 1), y se cree una categoría separada en el artículo 3 para esos documentos. Los informes de

los peritos y las declaraciones de los testigos se harán públicos a solicitud de cualquier persona, de conformidad con el artículo 7 (A/CN.9/760, párrs. 20 a 22). Las pruebas correspondientes a esos documentos estarían sujetas a una solicitud especial de conformidad con las disposiciones del artículo 3 3), al igual que las pruebas de los escritos de demanda y contestación u otras presentaciones (A/CN.9/760, párr. 20).

Párrafo 3) – Otros documentos

32. En el párrafo 3) aparece reflejada la decisión del Grupo de Trabajo adoptada en su 57º período de sesiones de que el tribunal arbitral, de oficio o a solicitud de una parte litigante o de una persona que no fuera parte litigante, tuviera la facultad discrecional para decidir si y cómo se haría público todo otro documento presentado al tribunal arbitral o que él mismo emita, que no estuvieran previstos en el párrafo 1) ni en el párrafo 2) (A/CN.9/760, párrs. 28 a 30). (Como consecuencia, los párrafos 2) y 3) del artículo 3, contenidos en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169, párr. 29, han sido consolidados en un solo párrafo 3).) La última oración del párrafo 3) tiene por objeto dar orientación al tribunal arbitral en cuanto a las medidas alternativas para hacer públicos esos documentos en un lugar determinado.

Párrafo 4) – Comunicación de documentos al archivo

33. El párrafo 4) corresponde a una propuesta de texto aprobada por el Grupo de Trabajo en su 57º período de sesiones (A/CN.9/760, párrs. 34 y 35), que ha sido ligeramente modificada para asegurar su coherencia con el artículo 7.

Párrafo 1) a 4) – Relación con el artículo 7 (anterior artículo 8)

34. Para reflejar la decisión del Grupo de Trabajo adoptada en su 57º período de sesiones de que el artículo 3 se refiriese al artículo 7, las palabras iniciales de los párrafos respectivos en lugar de ser “A reserva de las excepciones enunciadas en” serían “A reserva de lo dispuesto en el artículo 7 (...)” (A/CN.9/760, párrs. 32 y 33).

Párrafo 5) - Gastos

35. El párrafo 5) es una disposición nueva en la que aparece reflejada la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo en su 57º período de sesiones según la cual cuando las personas que no fuesen partes litigantes solicitaran acceso a los documentos se les exigiría sufragar los gastos administrativos de ese acceso (como los de fotocopiado, envío o gastos similares) (A/CN.9/760, párr. 130).

Artículo 4. Presentaciones a cargo de terceros (anterior artículo 5)

36. Proyecto de artículo 4 - Presentaciones a cargo de terceros

“1. Tras consultar a las partes litigantes, el tribunal arbitral podrá permitir que una persona que no sea parte litigante y no sea una parte en el tratado (“tercero”) haga ante el tribunal una presentación por escrito relativa a cuestiones que sean objeto del litigio.

2. El tercero que desee hacer una presentación lo requerirá al tribunal arbitral y presentará por escrito la información siguiente en uno de los idiomas del arbitraje, de manera concisa y respetando el límite de páginas que

pueda determinar el tribunal: a) descripción del tercero, indicando, si procede, la organización de que sea miembro y su condición jurídica (por ejemplo, asociación profesional u otra entidad no gubernamental), sus objetivos generales, la índole de sus actividades, y toda entidad matriz (incluida toda entidad que controle directa o indirectamente al tercero); b) revelación de si el tercero tiene o no algún tipo de afiliación, directa o indirecta, con alguna parte litigante; c) información sobre todo gobierno, persona u organización que haya prestado al tercero i) ayuda financiera o de otra índole para la preparación de la presentación, o ii) ayuda considerable en cualquiera de los dos años anteriores a la solicitud, como, por ejemplo la financiación de aproximadamente el 20% de sus operaciones globales anualmente; d) descripción de la índole del interés del tercero en el arbitraje; y e) indicación de las cuestiones de hecho y de derecho suscitadas en el arbitraje que el tercero desee abordar en su presentación escrita.

3. Para determinar si permite esa presentación, el tribunal arbitral tomará en consideración, entre otras cosas: a) si el tercero tiene un interés significativo en las actuaciones arbitrales, y b) la medida en que la presentación pueda ayudar al tribunal arbitral en la determinación de alguna cuestión de hecho o de derecho relativa a las actuaciones arbitrales, al aportar perspectivas, conocimientos particulares o puntos de vista distintos a los de las partes litigantes.

4. La presentación hecha por escrito por el tercero deberá: a) estar fechada y firmada por la persona que la presente; b) ser concisa y, en ningún caso deberá exceder la extensión autorizada por el tribunal arbitral; c) enunciar, en términos precisos, la posición del tercero respecto de las cuestiones en litigio; y d) tratar únicamente de cuestiones en litigio.

5. El tribunal arbitral deberá cerciorarse de que la presentación no perturbe el curso de las actuaciones ni les suponga una carga innecesaria, ni cause algún perjuicio indebido a ninguna de las partes litigantes.

6. El tribunal arbitral deberá cerciorarse de que se dé a las partes litigantes una oportunidad razonable de formular observaciones acerca de la presentación hecha por el tercero.”

Observaciones

37. El artículo 4 aborda las presentaciones a cargo de terceros y establece un procedimiento detallado sobre la información que debe aportarse respecto de los terceros que deseen hacer una presentación (párrafo 2)), las cuestiones que debe examinar el tribunal arbitral (párrafos 3), 5) y 6)), y la presentación misma (párrafo 4)). Está basado en las decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo en su 57º período de sesiones, como sigue: fue aprobado el contenido de los párrafos 1), 3), 4) y 5) sin modificaciones (A/CN.9/760, párrs. 42, 53, 55 y 56); el párrafo 2) corresponde a un proyecto de propuesta aprobado por el Grupo de Trabajo (A/CN.9/760, párrs. 43 a 51); y el párrafo 6) incluye una propuesta de formulación aprobada por el Grupo de Trabajo de suprimir la palabra “también” (A/CN.9/760, párr. 57) e incluir la palabra “razonable” después de la palabra “oportunidad” (A/CN.9/760, párr. 74).

Artículo 5. Presentaciones por partes en el tratado que no sean litigantes (*anterior artículo 6*)

38. Proyecto de artículo 5 – Presentaciones por partes en el tratado que no sean litigantes.

“1. El tribunal arbitral [permitirá] [podrá permitir] de partes en el tratado que no sean litigantes presentaciones sobre cuestiones relacionadas con la interpretación del tratado, o bien, tras celebrar consultas con las partes litigantes, invitarlas a que las hagan.

2. El tribunal arbitral, tras celebrar consultas con las partes litigantes, podrá permitir presentaciones sobre otras cuestiones que sean objeto del litigio, de partes en el tratado que no sean litigantes, o bien invitarlas a que las hagan. En el ejercicio de sus facultades discrecionales respecto de aceptar tales presentaciones o invitar a que se las haga, el tribunal arbitral tendrá en cuenta, entre otras cosas, los factores mencionados en el artículo 4, párrafo 3.

3. El tribunal arbitral no sacará conclusión alguna de la falta de presentación o respuesta ante una invitación formulada con arreglo a lo establecido en los párrafos 1 o 2.

4. El tribunal arbitral asegurará que las presentaciones no perturben las actuaciones arbitrales ni les supongan una carga innecesaria ni causen algún perjuicio indebido a alguna de las partes litigantes.

5. El tribunal arbitral asegurará que se dé a las partes litigantes una oportunidad razonable de hacer observaciones acerca de las presentaciones hechas por las partes en el tratado que no sean litigantes.”

Observaciones

39. En su 55º período de sesiones, el Grupo de Trabajo tomó nota del amplio acuerdo que había respecto de: i) abordar las presentaciones de una parte en el tratado que no sea litigante en una disposición separada de la relativa a las presentaciones de terceros (A/CN.9/736, párrs. 83, 84 y 97); ii) establecer que el tribunal arbitral debe celebrar consultas con las partes litigantes cuando ejerza sus facultades discrecionales; y iii) permitir que las partes litigantes expongan sus observaciones respecto de las presentaciones (A/CN.9/736, párr. 97).

Párrafo 1) – Cuestión para seguir siendo examinada: “[permitirá] [podrá permitir]”

40. El Grupo de Trabajo aceptó seguir examinando si el tribunal arbitral debía contar con facultades discrecionales para aceptar las presentaciones hechas por una parte en el tratado que no fuera litigante y, en consecuencia, si la expresión “permitirá” debería reemplazarse por la expresión “podrá permitir” (A/CN.9/736, párrs. 90 y 98; A/CN.9/760, párrs. 59 a 63). El Grupo de Trabajo invitó a los Estados a que examinaran sus tratados para determinar si contenían disposiciones que otorgaran a la parte no litigante el derecho a presentar al tribunal su opinión sobre la interpretación del tratado (A/CN.9/760, párr. 63).

Párrafo 2)

41. En sus 55º y 57º períodos de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó ampliamente si, además de presentaciones sobre cuestiones relacionadas con la interpretación del tratado, una parte en el tratado que no fuera litigante podía hacer presentaciones respecto de cuestiones que fueran objeto del litigio (A/CN.9/736, párrs. 85 a 89 y 98) y (A/CN.9/760, párrs. 64 a 67). El párrafo 2) refleja la decisión del Grupo de Trabajo de que una parte en el tratado no litigante también pudiera hacer presentaciones sobre cuestiones que fueran objeto del litigio (A/CN.9/760, párr. 67), pero no contiene ninguna disposición expresa para que el tribunal invite a hacer presentaciones (A/CN.9/760, párr. 70).

Párrafos 3) y 4)

42. En su 57º período de sesiones el Grupo de Trabajo aprobó sin modificaciones el contenido de los párrafos 3) y 4) (A/CN.9/760, párrs. 72 y 73).

Párrafo 5)

43. Conforme a la propuesta aceptada en relación con el artículo 4 6), que figura en el párrafo 37 del presente documento se suprimió del texto del párrafo 5) la palabra “también”. Además, se introdujo la palabra “razonable” después de la palabra “oportunidad”. Con esas modificaciones fue aprobado el contenido del párrafo 5) por el Grupo de Trabajo en su 57º período de sesiones (A/CN.9/760, párrs. 74 y 75).

Artículo 6. Audiencias (anterior párrafo 7)

44. Proyecto de artículo 6 – Audiencias

“1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 6, párrafos 2 y 3, las audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales (“audiencias”) serán públicas, a menos que el tribunal decida otra cosa tras celebrar consultas con las partes litigantes.

2. Cuando sea necesario proteger la información confidencial o la integridad del proceso arbitral con arreglo a lo establecido en el artículo 7, el tribunal arbitral adoptará disposiciones para celebrar en privado la parte de la audiencia que deba ser protegida.

3. El tribunal arbitral podrá adoptar disposiciones logísticas para facilitar el acceso del público a las audiencias (incluso, según proceda, organizando la asistencia mediante enlaces de vídeo u otros medios de este tipo que estime conveniente) y podrá, tras celebrar consultas con las partes, decidir que toda la audiencia o parte de ella se celebre en privado cuando sea o se haga necesario por motivos logísticos.”

Observaciones**Párrafo 1) – Cuestión para seguir examinando: audiencias públicas**

45. En el 57º período de sesiones del Grupo de Trabajo, se expresó considerable apoyo al principio de que la norma preestablecida seguiría siendo la de que las audiencias fueran públicas, con arreglo al Reglamento, a reserva únicamente de

las excepciones mencionadas en los párrafos 2) y 3), si bien algunas delegaciones apoyaron la opinión de que las partes litigantes deberían tener el derecho unilateral a pedir que las audiencias fueran en privado. Para poder pasar a la segunda lectura, se acordó en última instancia examinar el párrafo 1) en deliberaciones ulteriores (A/CN.9/760, párr. 82).

Párrafos 2) y 3) – Excepciones a la celebración de audiencias públicas

46. Los párrafos 2) y 3) aportan orientaciones respecto de las excepciones al principio de que las audiencias deban ser públicas. El párrafo 2) se refiere a las excepciones contenidas en el artículo 7. El párrafo 3) aborda las inquietudes expresadas en el Grupo de Trabajo de que quizás las audiencias tengan que celebrarse en privado, por razones prácticas, tales como cuando debido a las circunstancias no puede adoptarse ninguna disposición logística viable para permitir el acceso del público a las audiencias (A/CN.9/717, párr. 109 y A/CN.9/736, párr. 104).

“Audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales”

47. Las palabras “para la presentación de pruebas o para alegatos orales” fueron añadidas después de la palabra “audiencias” en el párrafo 1) para aclarar que las audiencias deberían ser públicas cuando en ellas se abordaran cuestiones sustantivas (en particular, audiencias relativas a cuestiones jurisdiccionales y audiencias en las que se presentaran declaraciones de testigos o de peritos, o argumentos orales), pero no cuando se trataran simples cuestiones de procedimiento (A/CN.9/760, párrs. 86 y 88). Estas palabras reflejan la formulación del párrafo 1 del artículo 24 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.

(A/CN.9/WG.II/WP.176 y Add.1) (Original: inglés)

**Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales:
preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los
arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco
de un tratado, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje
y Conciliación en su 58º período de sesiones**

ADICIÓN

Índice

	<i>Párrafos</i>
II. Proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (<i>continuación</i>) . .	1-13
B. Contenido del proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (<i>continuación</i>)	1-13
Artículo 7. Excepciones a la norma de la transparencia	1-8
Artículo 8. Archivo de la información publicada (anterior artículo 9)	9-11
Cuestión general de los costos	12-13
III. Instrumentos para la aplicación de la norma jurídica sobre la transparencia a los tratados de inversiones	14-34
A. Posibles instrumentos de la CNUDMI	16-30
B. Medidas que podrían adoptar los Estados	31-34

**II. Proyecto de reglamento sobre la transparencia en los
arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el
marco de un tratado (*continuación*)**

**B. Contenido del proyecto de reglamento sobre la transparencia en los
arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un
tratado (*continuación*)**

Artículo 7. Excepciones a la norma de la transparencia (*anterior artículo 8*)

1. Proyecto de artículo 7 - Excepciones a la norma de la transparencia

Información confidencial o protegida

“1 La información confidencial o protegida, como se define en el párrafo 2 y se determina en cumplimiento de las disposiciones a que se hace referencia en los párrafos 3 y 4, no se pondrá a disposición del público ni de las partes en el tratado que no sean litigantes con arreglo a los artículos 2 a 6.

2. *La información confidencial o protegida consiste en:*

a) *Información comercial confidencial;*

b) *Información que no debe ponerse a disposición del público, con arreglo al tratado; o*

Opción 1: *[c) Información que no debe ponerse a disposición del público, con arreglo a cualquier ley o reglamento que, a juicio del tribunal arbitral, sea aplicable a la revelación de esa clase de información.]*

Opción 2: *[c) Información que no debe ponerse a disposición del público, en el caso de la información del demandado, con arreglo a la legislación del demandado, y en el caso de información de otro tipo, con arreglo a cualquier ley o reglamento que el tribunal arbitral determine aplicable a la revelación de esa clase de información.]*

Opción 3: *[c) Información que no debe ponerse a disposición del público, con arreglo a cualquier ley o reglamento que, a juicio del tribunal arbitral, sea aplicable a la revelación de esa clase de información, habida cuenta de la legislación aplicable del demandado al examinar la información revelada por el demandado.]*

[d) Información que ambas partes litigantes acuerden no poner a disposición del público, a menos que ello atente contra el interés público.]

[2 bis) Nada de lo dispuesto en el presente reglamento obligará a una parte litigante a facilitar [al público] información cuya revelación estime que impediría la aplicación de la ley o sería contraria al interés público o a sus intereses de seguridad esenciales.]

3. *El tribunal arbitral, en consulta con las partes litigantes, tomará disposiciones para impedir que cualquier información confidencial o protegida sea puesta a disposición del público o de las partes en el tratado no litigantes inclusive estableciendo, según proceda a) plazos para que una parte litigante, una parte en el tratado no litigante o una tercera persona indique que desea proteger dicha información en un documento, b) procedimientos para declarar con rapidez que la información de que se trate es confidencial o se halla protegida en esos documentos y c) procedimientos para celebrar audiencias en privado, en la medida en que ello se prevea en el artículo 6, párrafo 2. El tribunal arbitral decidirá, previa consulta con las partes, si determinada información es confidencial o protegida.*

4. *Si el tribunal arbitral determina que esa información no debe suprimirse de un documento, o que no debe impedirse que un documento se haga público, cualquier parte litigante, parte en el tratado no litigante o un tercero que en forma voluntaria introduzca el documento en el archivo podrá retirar el documento o una parte de este de las actuaciones arbitrales.*

Integridad del proceso arbitral

5. *La información no se hará pública con arreglo a los artículos 2 a 6 cuando la información, si puesta a disposición del público, pudiera poner en*

peligro la integridad del proceso arbitral, según se determine de conformidad con el párrafo 6.

6. El tribunal podrá, de oficio o a solicitud de una parte litigante, previa consulta con las partes litigantes cuando fuere practicable, adoptar las medidas necesarias para limitar o demorar la publicación de información, cuando tal publicación pueda poner en peligro la integridad del proceso arbitral porque: a) podría dificultar la reunión o presentación de pruebas, o b) podría dar lugar a la intimidación de testigos, abogados de las partes litigantes o miembros del tribunal arbitral, o c) en circunstancias comparablemente excepcionales.”

Observaciones

2. El propósito del artículo 7 es definir las excepciones a la norma de transparencia, que se limitan a la protección de la información confidencial o protegida (párrafos 1) a 4)) y la protección de la integridad del proceso arbitral (párrafos 5) y 6)) (A/CN.9/717, párrs. 129 a 147; A/CN.9/736, párrs. 110 a 130; A/CN.9/760, párrs. 89 a 119).

Información confidencial o protegida

3. Los párrafos 1) a 4) reflejan un proyecto de propuesta examinado por el Grupo de Trabajo en su 57º período de sesiones e incluyen las modificaciones de redacción acordadas por el Grupo de Trabajo (A/CN.9/760, párrs. 89 a 119).

Párrafo 2) - Cuestiones para seguir examinando

- Párrafo 2) c)

4. El Grupo de Trabajo quizás desee examinar las tres opciones correspondientes al párrafo 2) c) que reflejan las distintas opiniones expresadas en su 57º período de sesiones: i) la opción 1, con arreglo a la cual se otorgaría al tribunal facultad discrecional para realizar un análisis de conflicto de leyes respecto de toda la información; ii) opción 2, con arreglo a la cual se remite al tribunal a la legislación del demandado respecto de la información del demandado, y a un análisis sobre conflicto de leyes respecto de toda la demás información; y iii) la opción 3, con arreglo a la cual se da al tribunal orientación para que, en su análisis sobre conflicto de leyes respecto de cuestiones relacionadas con la información del demandado, tenga particularmente en cuenta la legislación del demandado (A/CN.9/760, párr. 104).

- Párrafo 2) d)

5. El párrafo 2) d) corresponde a una propuesta formulada en el 57º período de sesiones del Grupo de Trabajo. Se expresó cierto apoyo a esa propuesta, aunque algunas delegaciones se opusieron resueltamente a la sugerencia, y se convino en seguir examinándola durante la tercera lectura del reglamento (A/CN.9/760, párr. 117).

- *Párrafo 2) bis*

6. En el 57º período de sesiones del Grupo de Trabajo se propuso una nueva disposición, provisionalmente numerada párrafo 2) *bis*, para seguir examinándola (A/CN.9/760, párrs. 105 a 109). Se dijo que esta disposición no tenía por objeto ser una nueva excepción en virtud del artículo 7, sino que era una cuestión que una parte (en particular un Estado Parte litigante) podría determinar para sí (A/CN.9/760, párr. 106). El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar en qué medida la cuestión ya había sido abordada en el marco del párrafo 2) c) (A/CN.9/760, párrs. 108 y 109).

Procedimiento para proteger la integridad del proceso arbitral

7. En el 53º período de sesiones del Grupo de Trabajo, se había reconocido en general que la cuestión de la protección de la integridad del proceso arbitral debía tenerse en cuenta como parte del debate sobre las limitaciones impuestas a la transparencia (A/CN.9/712, párr. 72).

8. El contenido de los párrafos 5) y 6), en que se define un procedimiento para la protección de la integridad del proceso arbitral, fue aprobado por el Grupo de Trabajo en su 57º período de sesiones (A/CN.9/760, párrs. 118 y 119).

Artículo 8. Archivo de la información publicada (anterior artículo 9)

9. Proyecto de artículo 8 - Archivo de la información publicada

Opción 1

“--- se encargará de poner a disposición del público la información relativa al Reglamento sobre la Transparencia. [Habrá que determinar otros servicios, como el almacenamiento de documentos.]”

Opción 2

1. Si las actuaciones arbitrales son administradas por una institución de arbitraje, la institución se encargará de poner la información a disposición del público con arreglo al Reglamento sobre la Transparencia. [Habrá que determinar otros servicios, como el almacenamiento de documentos.]

2. Si las actuaciones arbitrales no son administradas por una institución de arbitraje, el demandado deberá designar una institución de arbitraje entre las que figuran en la lista de instituciones del anexo, que desempeñará las funciones mencionadas en el párrafo 1.”

Observaciones

10. En su 54º período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó la cuestión de si el establecimiento de un archivo neutral (también llamado “registro”) debía considerarse una medida necesaria en la promoción de la transparencia en los arbitrajes entablados en el marco de un tratado, entre inversionistas y Estados (A/CN.9/717, párrs. 148 a 151). La opinión predominante fue que la existencia de un registro sería crucial para contar con el nivel necesario de neutralidad en la administración de una norma jurídica sobre la transparencia. Se expresó apoyo general a la idea de que, en caso de establecerse ese registro neutral, la Secretaría de las Naciones Unidas sería el lugar ideal para instalarlo. También se recordó que,

si las Naciones Unidas no estuvieran en condiciones de asumir esa función, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) habían expresado su disposición a prestar esos servicios de registro (A/CN.9/717, párr. 148).

11. En el 55º periodo sesiones del Grupo de Trabajo se formularon varias propuestas (A/CN.9/736, párrs. 131 a 133). Una fue el establecimiento de un registro único, según figura en la opción 1. Otra propuesta fue establecer una lista de instituciones de arbitraje que podrían desempeñar la función de registro, según figura en la opción 2 (A/CN.9/736, párr. 131). El Grupo de Trabajo no llegó a un consenso respecto de cuál de las dos opciones allí señaladas era preferible. La decisión correspondiente se aplazó hasta un futuro período de sesiones. No obstante, se convino, en principio, en que si el Grupo de Trabajo adoptaba en último término la opción 1, la CNUDMI sería la institución depositaria preferente para ocuparse del registro, si tuviera la capacidad de asumir esa función. Se convino también en que, si se designaba a varias instituciones para encargarse del registro, conforme a la opción 2, debería haber un sitio web central, de cuya creación se encargara preferiblemente la CNUDMI, y que sirviera como centro de información para vincular la función de registro de esas instituciones (A/CN.9/760, párrs. 120 y 121).

Cuestión general de los costos

Costos de las audiencias públicas

12. En respuesta a lo solicitado por el Grupo de Trabajo en su 55º período de sesiones (A/CN.9/736, párr. 106), el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) facilitó información sobre los gastos relacionados con la celebración de audiencias públicas, que figura en el documento A/CN.9/WG.II/WP.170/Add.1.

Costos relacionados con el establecimiento y mantenimiento de un registro

13. En su 55º período de sesiones, el Grupo de Trabajo invitó a las instituciones de arbitraje interesadas a aportar información sobre el costo de establecer y mantener un registro de la información que se publicaría de conformidad con el reglamento sobre la transparencia (A/CN.9/736, párr. 133). En cumplimiento de esa decisión, la Secretaría distribuyó un cuestionario a las instituciones de arbitraje que habían manifestado interés en asociarse a las actividades en curso del Grupo de Trabajo o de las que la CNUDMI tenía conocimiento de que tramitaban controversias entre inversionistas y Estados en virtud de un tratado¹. El cuestionario y las respuestas recibidas de las instituciones de arbitraje se reproducen en el documento A/CN.9/WG.II/WP.170 y su adición. La información presentada por la Secretaría de la CNUDMI figura en el documento A/CN.9/WG.II/WP.169, Add.1, párrs. 9 a 12.

¹ Véase *Latest Developments in Investor-State Dispute Settlement*, IIA Issues Nota núm. 1 (2010), International Investment Agreements, pág. 2; disponible el 28 de noviembre de 2011, en el sitio www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20103_en.pdf; véase también el documento A/CN.9/WG.II/WP.160, párr. 29.

III. Instrumentos para la aplicación de la norma jurídica sobre la transparencia a los tratados sobre inversiones ya existentes

14. En el 54º período de sesiones del Grupo de Trabajo, algunas delegaciones se declararon partidarias de la opción consistente en preparar un instrumento, que una vez adoptado por los Estados, pudiera hacer aplicable la norma jurídica de la transparencia a los tratados ya existentes. Se sostuvo que esa cuestión tenía importantes repercusiones prácticas, pues a la fecha había en vigor más de 2.500 tratados de inversiones (A/CN.9/712, párr. 85 y A/CN.9/717, párrs. 33 a 35)². En su 55º período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó diversos instrumentos mediante los cuales el reglamento sobre la transparencia pudiera ser aplicable a los tratados de inversiones existentes, conforme a lo expuesto en los párrafos 10 a 23 del documento A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1. Los instrumentos incluían: i) una recomendación por la que se instaba a los Estados a que dieran aplicabilidad al Reglamento en el contexto de la solución de controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado; ii) una convención en virtud de la cual los Estados pudieran consentir en la aplicación del reglamento sobre la transparencia a arbitrajes regidos por sus tratados de inversiones existentes; y iii) declaraciones interpretativas conjuntas hechas de conformidad con el artículo 31 3) a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (“la Convención de Viena”) o una enmienda o modificación hecha de conformidad con los artículos 39 a 41 de la Convención de Viena (A/CN.9/736, párrs. 143 y 135).

15. Conforme a lo solicitado por el Grupo de Trabajo en su 57º período de sesiones (A/CN.9/760, párrs. 12 y 141), la presente nota contiene el texto de un proyecto de convención sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado de inversiones, así como de un modelo de declaración unilateral (véanse más adelante los párrafos 17 y 34, respectivamente). El Grupo de Trabajo quizás desee examinar la propuesta de redacción elaborada por la Secretaría en el documento A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1 relativa a la opción de una recomendación en la que se instaba a los Estados a hacer la norma jurídica aplicable en el contexto de la solución de controversias, entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado, así como con respecto a las opciones de hacer aplicable la norma jurídica sobre la transparencia a los tratados existentes mediante declaraciones interpretativas conjuntas hechas de conformidad con el artículo 31 3) a) de la Convención de Viena o mediante una enmienda o modificación con arreglo a los artículos 39 a 41 de la Convención de Viena.

A. Posibles instrumentos de la CNUDMI

16. Los posibles instrumentos que la CNUDMI puede preparar y promover para la aplicación de la norma jurídica sobre la transparencia a los tratados concertados antes de la fecha de aprobación del reglamento sobre la transparencia incluyen una recomendación y una convención. En el documento A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1,

² Para una recopilación en línea de todos los tratados de inversiones, véase la base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que, al 20 de julio de 2011, se podía consultar en www.unctadxi.org/templates/Startpage_718.aspx.

párrafos 12 a 14, figura el texto de un proyecto de recomendación, con observaciones.

17. En su 57º período de sesiones, el Grupo de Trabajo dio instrucciones a la Secretaría de que preparara un texto más detallado de una convención sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, a fin de incluir un proyecto de cláusula que permitiera formular una reserva a esa convención (A/CN.9/760, párrs. 12 y 141). El texto de un posible proyecto de convención sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado podría ser el siguiente.

Proyecto de texto

“Las Partes en la presente Convención,

Reafirmando su convicción de que el comercio internacional basado en la igualdad y el provecho mutuo constituye un factor importante en orden al fomento de las relaciones amistosas entre los Estados,

Convencidas de que la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional, al reducir o eliminar los obstáculos jurídicos que dificultan el curso del comercio internacional, contribuyen de modo notable a la cooperación económica universal entre todos los Estados sobre una base de igualdad e interés común, así como al bienestar de todos los pueblos,

Reconociendo el valor del arbitraje como método para resolver las controversias que puedan surgir en el contexto de las relaciones internacionales y la utilización amplia y generalizada del arbitraje para la solución de controversias entre inversionistas y Estados,

Reconociendo también la necesidad de disposiciones sobre la transparencia en la solución de controversias entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado, a fin de tener en cuenta el interés público afectado por dichos arbitrajes,

Convencidas de que el Reglamento sobre la Transparencia aprobado por la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) el [fecha] contribuiría considerablemente al establecimiento de un marco jurídico armonizado para resolver de forma equitativa y eficiente las controversias internacionales [en materia de inversiones],

Observando el gran número de tratados de inversiones que ya están en vigor y la importancia práctica de promover la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia al arbitraje entablado en el marco de esos tratados de inversiones ya celebrados,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1. La presente Convención se aplicará al arbitraje entre inversionistas y Estados entablado de conformidad con un tratado que prevea la protección de

las inversiones o los inversionistas entre las Partes Contratantes en la presente Convención.

2. La expresión “tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas” significa todo acuerdo de inversiones celebrado entre Partes Contratantes, incluidos acuerdos de libre comercio, acuerdos de integración económica, acuerdos marco de comercio o inversiones o de cooperación y tratados bilaterales y multilaterales de inversiones, en la medida en que contengan disposiciones sobre la protección de las inversiones o los inversionistas y el derecho de los inversionistas a recurrir al arbitraje contra las partes en el tratado.

Artículo 2

Interpretación

En la interpretación de la presente Convención se deberá tener presente su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y la observancia de la buena fe en el comercio internacional.

Artículo 3

Utilización del Reglamento sobre la Transparencia de la CNUDMI

“Cada una de las Partes Contratantes conviene en que el Reglamento sobre la Transparencia de la CNUDMI será aplicable al arbitraje entre inversionistas y Estados entablado de conformidad con un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas entre las Partes Contratantes en la presente Convención. Nada de lo dispuesto en la presente Convención impide a las Partes Contratantes aplicar normas que establezcan un grado de transparencia mayor que el previsto en el Reglamento sobre la Transparencia.

Artículo 4

Reservas

1. Una Parte Contratante puede declarar que ciertos tratados de inversiones no pertenecen al ámbito de la presente Convención. No se permite ninguna otra reserva a la presente Convención.
2. Las reservas efectuadas en el momento de la firma estarán sujetas a confirmación en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación.
3. Las reservas y sus confirmaciones deberán ser notificadas oficialmente al depositario.
4. Las reservas surtirán efecto simultáneamente a la entrada en vigor de la presente Convención con respecto a la Parte Contratante de que se trate. Una reserva que sea notificada oficialmente al depositario con posterioridad a dicha entrada en vigor surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración del plazo de [seis] meses después de la fecha de su recepción por el depositario.
5. Toda Parte que haga una reserva a la presente Convención podrá modificarla o retirarla en cualquier momento mediante una notificación oficial

por escrito enviada al depositario. La modificación o retiro surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración del plazo de [seis] meses después de la fecha en que el depositario reciba la notificación al respecto.

Artículo 5

Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.

Artículo 6

Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. La presente Convención estará abierta a la firma de toda parte en un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas hasta [fecha].
2. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación y aprobación por las partes signatarias.
3. La presente Convención estará abierta a la adhesión de toda entidad mencionada en el artículo 7, párrafo 1), desde la fecha en que quede abierta a la firma.
4. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del depositario.

Artículo 7

Aplicación a las unidades territoriales de los Estados

1. Todo Estado Contratante integrado por dos o más unidades territoriales en las que sea aplicable un régimen jurídico distinto en relación con las materias objeto de la presente Convención podrá declarar, en el momento de su firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a la presente Convención, que esta será aplicable a todas sus unidades territoriales, o solo a una o varias de ellas, y podrá en cualquier momento sustituir por otra su declaración original.
2. En esas declaraciones, que deberán notificarse al depositario, se hará constar expresamente a qué unidades territoriales será aplicable la Convención.
3. Cuando un Estado Contratante haya declarado, conforme a lo previsto en este artículo, que la presente Convención será aplicable a una o más de sus unidades territoriales, pero no a todas, se considerará, para los fines de la presente Convención, que todo lugar situado en una unidad territorial a la que la Convención no sea aplicable no está situado en un Estado Contratante.
4. Si un Estado Contratante no hace ninguna declaración conforme al párrafo 1 del presente artículo, la Convención será aplicable a todas las unidades territoriales de ese Estado.

Artículo 8

Participación de organizaciones regionales de integración económica

1. Toda organización regional de integración económica que esté constituida por Estados soberanos y que goce de competencia sobre ciertos asuntos que se rijan por la presente Convención podrá igualmente firmar, ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención o adherirse a ella. La organización regional de integración económica tendrá, en ese caso, los derechos y las obligaciones de un Estado Contratante en la medida en que goce de competencia sobre algún asunto que se rija por la presente Convención. En toda cuestión respecto de la que, en el marco de la presente Convención, resulte relevante el número de Estados Contratantes, la organización regional de integración económica no contará como Estado Contratante que deba añadirse al número de sus Estados miembros que sean Estados Contratantes.
2. La organización regional de integración económica deberá hacer, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, una declaración ante el depositario en la que se hagan constar los asuntos que se rijan por la presente Convención respecto de los cuales sus Estados miembros le hayan transferido su competencia. La organización regional de integración económica notificará con prontitud al depositario todo cambio en la distribución de las competencias, con inclusión de toda nueva competencia que le haya sido transferida, mencionada en la declaración con arreglo a este párrafo.
3. Toda referencia que se haga en la presente Convención a una “Parte Contratante” o a las “Partes Contratantes” será igualmente aplicable a una organización regional de integración económica cuando el contexto así lo requiera.

Artículo 9

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración del plazo de [seis] meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el tercer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Cuando un Estado ratifique, acepte, apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de que se haya depositado el tercer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor respecto de ese Estado el primer día del mes siguiente a la expiración del plazo de [seis] meses contado a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 10

Momento de aplicación

La presente Convención y toda declaración o reserva solo se aplicarán a los procedimientos arbitrales que se hayan iniciado después de la fecha en que

entre en vigor la Convención o surta efecto la declaración o reserva respecto de cada Parte Contratante.

Artículo 11

Revisión y enmienda

1. De solicitarlo por lo menos un tercio de las Partes Contratantes, el Secretario General de las Naciones Unidas deberá convocar una conferencia de las Partes Contratantes en la presente Convención para proceder a su revisión o enmienda.
2. Se entenderá que todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o cualquier reserva que sean depositados después de la entrada en vigor de una enmienda a la presente Convención se aplica al texto enmendado de la Convención.

Artículo 12

Denuncia de la presente Convención

1. Toda Parte Contratante podrá denunciar la presente Convención en cualquier momento mediante notificación hecha por escrito al depositario. La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración del plazo de un año contado desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el depositario.
2. La presente Convención se seguirá aplicando al arbitraje cuyas actuaciones arbitrales hayan comenzado antes de que surta efecto la denuncia.

HECHO en [lugar], el [fecha], en un solo original, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados [por sus respectivos Gobiernos], han firmado la presente Convención.”

Observaciones

Proyecto de artículo 1

18. El proyecto de artículo 1 se refiere al ámbito de aplicación de la Convención sobre la Transparencia y prevé que la Convención se aplicará a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado de inversiones cuando las partes en el tratado de inversiones sean también partes contratantes en la Convención sobre la Transparencia. Esto está en consonancia con el entendimiento expresado por el Grupo de Trabajo en su 55º período de sesiones de que una convención de esa naturaleza haría que las normas sobre transparencia fueran aplicables únicamente a los tratados de inversiones entre los Estados parte (u organizaciones regionales de integración económica) que también fueran Partes en la Convención sobre la Transparencia (A/CN.9/736, párr. 135).

19. El Grupo de Trabajo quizás desee examinar el artículo 1 del proyecto de Convención en relación con el artículo 1 del proyecto de Reglamento sobre la Transparencia, de manera de mantener, en la medida de lo posible, la coherencia

entre el ámbito de aplicación de ambos instrumentos. Puede observarse que la definición de un “tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas” es similar a la definición del artículo 1 del proyecto de Reglamento sobre la Transparencia.

- Partes

20. En su actual formulación, la Convención sobre la Transparencia solo se aplica a los tratados de inversiones concertados entre partes que también sean Partes en la Convención sobre la Transparencia (véase *supra*, párr. 18). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si, en caso de que un tratado de inversiones tenga signatarios múltiples, solo algunos de los cuales sean Partes Contratantes en la Convención sobre la Transparencia, si esta Convención debería aplicarse en las controversias entre una Parte Contratante en esta Convención y un nacional de otra Parte Contratante. Si el Grupo de Trabajo considera que se trata de una cuestión de principio, el Reglamento sobre la Transparencia deberá ser aplicable en ese caso y la formulación de los proyectos de artículos 1 y 3 quizás debería modificarse para reflejar dicha posibilidad.

- Reglamento de arbitraje

21. El Grupo de Trabajo quizás desee tomar nota de que la Convención se aplicaría a cualquier arbitraje de un Estado inversor iniciado en el marco de un tratado independientemente del conjunto de normas institucionales o normas de arbitraje *ad hoc* aplicables a la solución de la controversia.

Proyecto de artículo 2

22. Los principios enunciados en el proyecto de artículo 2 se han empleado en la mayoría de los textos de la CNUDMI, y su formulación refleja el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa. Esta disposición tiene por objeto facilitar la interpretación uniforme de las disposiciones de los instrumentos uniformes de derecho mercantil.

Proyecto de artículo 3

23. La opción de una convención en forma de una declaración general de aplicabilidad según se propone en la presente nota, no incorpora el contenido del Reglamento sobre la Transparencia que actualmente prepara el Grupo de Trabajo, pero refleja el acuerdo de las Partes Contratantes de aplicar esas normas a los arbitrajes celebrados con arreglo a sus tratados vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Convención. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si en el artículo 3 se debería aclarar la versión del Reglamento sobre la Transparencia que está incluido como referencia en caso de que dicho Reglamento sea revisado. El Grupo de Trabajo tal vez desee seguir examinando si la Convención también debería incluir el texto del Reglamento sobre la Transparencia (A/CN.9/736, párr. 135; véase también A/CN.9/WP.166/Add.1, párr. 39).

Proyecto de artículo 4

24. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar su decisión adoptada en el 57º período de sesiones de que se incluyera una reserva en la Convención sobre la

Transparencia (A/CN.9/760, párr. 141). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la reserva autorizada con arreglo al párrafo 1) en su actual redacción, y si el ámbito de esta reserva debería seguir siendo amplio o definirse más con mayor precisión.

25. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si debería enumerarse cualquier otra reserva, o si la Convención debería prohibir reservas adicionales. El Grupo de Trabajo quizás desee examinar a este respecto el artículo 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

Proyectos de artículos 5 a 12 - Disposiciones finales

26. Las disposiciones de los proyectos de artículos 5 a 12 son cláusulas que se incluyen habitualmente al final de los tratados multilaterales y que no tienen por objeto crear ningún derecho u obligación entre las partes privadas. No obstante, dado que estas disposiciones regulan la medida en que una Parte Contratante quedará vinculada por la Convención, así como el momento en que entrará en vigor la Convención o toda declaración que se efectúe en el marco de lo previsto en ella, determinarán la confianza depositada por las partes litigantes en las disposiciones de la Convención.

- Proyecto de artículo 7

27. El proyecto de artículo 7 faculta a todo Estado Contratante para declarar, en el momento de dar su firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que la Convención será aplicable a todas sus unidades territoriales, o solo a una o varias de ellas, facultándole además para sustituir, en cualquier momento, por otra, su declaración original. Esta disposición, que suele llamarse “cláusula federal”, interesa a un número relativamente reducido de Estados -sistemas federales en que el gobierno central no posee la facultad de establecer una normativa legal uniforme sobre las materias reguladas por la Convención. El efecto de la disposición es, por un lado, facultar a todo Estado federal para aplicar progresivamente el régimen de la Convención en sus unidades territoriales y, por otro, facultar a los Estados que lo deseen para extender desde un principio su aplicación a todas sus unidades territoriales. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si es necesario que figure esa disposición.

- Proyecto de artículo 8

28. Además de los “Estados”, la Convención permite la participación de cierto tipo de organizaciones internacionales que son partes en tratados de inversiones, a saber, “organizaciones regionales de integración económica”. El texto de la Convención no contiene una definición de “organización regional de integración económica”. Habitualmente, la noción de “organización regional de integración económica” abarca dos elementos esenciales: la de ser una agrupación de Estados de determinada región para el logro de una meta común, y la de que sus miembros transfieran a la organización así formada ciertas competencias al servicio de la meta perseguida.

- Proyecto de artículo 9

29. Las disposiciones básicas relativas a la entrada en vigor de la Convención se enuncian en el proyecto de artículo 9. Las tres ratificaciones corresponden a la

tendencia observable en el derecho mercantil internacional moderno de favorecer una aplicación lo más temprana posible. Se ha prescrito un plazo de seis meses desde la fecha en que se deposite el tercer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a fin de dar a las Partes en la Convención el tiempo suficiente para notificar a todas las entidades nacionales y personas interesadas la pronta entrada en vigor de una convención cuyo régimen les afectará. El párrafo 2 se refiere a la entrada en vigor del proyecto de convención respecto de las partes contratantes que pasan a ser partes en la misma con posterioridad al momento de su entrada en vigor, con arreglo a lo previsto en el párrafo 1.

- Proyecto de artículo 10

30. Si bien el proyecto de artículo 9 se ocupa de la fecha de entrada en vigor de la Convención en lo relativo a las obligaciones internacionales que incumben a las Partes en virtud de la Convención, el proyecto de artículo 10 determina la fecha en que la Convención pasará a ser aplicable con respecto a los procedimientos arbitrales. La Convención solo será aplicable en el futuro, es decir a los procedimientos arbitrales que comiencen después de la fecha de su entrada en vigor. Las palabras “respecto de cada Parte Contratante” tienen por objeto dejar claramente establecido que el artículo se refiere a la fecha de la entrada en vigor de la Convención para cada Parte Contratante considerada, y no a la fecha de su entrada en vigor en general.

B. Medidas que podrían adoptar los Estados

31. En sus períodos de sesiones 53º y 54º, el Grupo de Trabajo examinó las posibles medidas que los Estados podrían adoptar para hacer que el Reglamento sobre la Transparencia fuese aplicable a los tratados de inversiones tanto bilaterales como multilaterales (A/CN.9/712, párrs. 85 y 86, A/CN.9/717, párrs. 42 a 46). En el 54º período de sesiones del Grupo de Trabajo, entre las posibles opciones para garantizar la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia a los tratados de inversiones ya existentes se mencionó una posible declaración interpretativa conjunta hecha por los Estados de conformidad con el artículo 31 3) a) de la Convención de Viena, así como una enmienda o modificación de los tratados con arreglo a los artículos 39 y siguientes de dicha Convención (A/CN.9/717, párrs. 42 a 45).

32. En el documento A/CN.9/WG.II/WP.161/Add.1, párrs. 22 y 23, se proponen modelos de tales instrumentos. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar que el documento A/CN.9/WG.II/WP.162 aborda las declaraciones conjuntas interpretativas y unilaterales, además de otras posibles medidas que podrían adoptar los Estados para asegurar la aplicabilidad del reglamento sobre la transparencia a los tratados de inversiones existentes (véase A/CN.9/WG.II/WP.162, párrs. 26 a 48).

33. También se propuso, en los 53º y 57º período de sesiones del Grupo de Trabajo, que la aplicabilidad del reglamento sobre la transparencia podría lograrse a través de declaraciones unilaterales de los Estados interesados (A/CN.9/712, párr. 93 y A/CN.9/760, párr. 141). El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar que había observado que la declaración de un único Estado no bastaría para hacer aplicable el Reglamento sobre la Transparencia a los tratados ya existentes, porque

un tratado nace de un acuerdo entre Estados parte (A/CN.9/712, párr. 93). Por consiguiente, los Estados parte en un tratado de inversiones necesitarían cada uno de ellos hacer declaraciones unilaterales con el mismo fin para aplicar la norma jurídica sobre transparencia a un tratado existente. Tales declaraciones unilaterales pasarían así a formar un acuerdo interpretativo subsiguiente entre los Estados parte relativo a la interpretación del tratado o la aplicación de sus disposiciones con arreglo al artículo 31 3) a) de la Convención de Viena, que prevé como regla general de interpretación que cualquier acuerdo subsiguiente entre las partes relativo a la interpretación del tratado o la aplicación de sus disposiciones se deberá tomar en consideración junto con el contexto. No obstante, no será preciso, para ese fin, dar a dichas declaraciones la forma de una declaración “conjunta”. Ahora bien, se habrá de dejar constancia del acuerdo entre las Partes sobre la interpretación del tratado, para lo que bastaría con proceder a un intercambio de notas. Conforme ha indicado la Comisión de Derecho Internacional en su proyecto de directrices sobre declaraciones concernientes a los acuerdos bilaterales³, una declaración interpretativa por un único Estado Parte en el tratado, podrá ser tenida por interpretación auténtica del tratado, si la otra Parte en el tratado la acepta⁴.

34. Un posible modelo de proyecto de declaración interpretativa conjuntas con arreglo al artículo 31 3) a) de la Convención de Viena podría ser el siguiente:

“Entendimiento del Gobierno de [] sobre la interpretación y aplicación de determinadas disposiciones del [] [nombre del tratado de inversiones]

Queda entendido que la [las] disposición [disposiciones] de los artículos [] del [] [nombre del tratado de inversiones] que permite [n] a un inversionista de un Estado Contratante iniciar un arbitraje contra otro Estado Contratante [con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI] en el marco de [] [nombre del tratado de inversiones] incluye [n] la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia de la CNUDMI.”

³ El proyecto de directrices relativas a las declaraciones concernientes a los acuerdos bilaterales están incluidas en el proyecto de directrices relativas a las reservas efectuadas a un tratado y a la interpretación auténtica de un tratado con arreglo al apartado 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena, preparado por la Comisión de Derecho Internacional, Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor de su 62º período de sesiones, *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 10* (A/65/10), pág. 40, disponible en <http://untreaty.un.org/ilc/reports/2010/2010report.htm>.

⁴ *Ibid.*, Proyecto de directrices 1.5.3.

G. Nota de la Secretaría relativa al establecimiento de un archivo de la información publicada (“registro”): solución de controversias comerciales: preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 58º período de sesiones

(A/CN.9/WG.II/WP.177)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-2
II. Establecimiento de un registro en el marco de proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	3-26
A. Opciones institucionales para un registro	3-11
B. Naturaleza y alcance del registro	12-13
C. Cuestiones que podría tratar el Grupo de Trabajo	14-26

I. Introducción

1. En la preparación del 58º período de sesiones del Grupo de Trabajo, y de conformidad con el mandato confiado por el Grupo de Trabajo a la Secretaría de que estableciera enlaces con otras instituciones arbitrales a fin de evaluar mejor el costo y otras repercusiones del establecimiento de un registro en el marco del proyecto de Reglamento sobre la Transparencia de la CNUDMI en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (el “Reglamento”) (A/CN.9/760, párr. 122), la Secretaría consultó a las siguientes instituciones arbitrales¹: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA), la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), y el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (las “instituciones arbitrales”). La presente nota expone las principales conclusiones extraídas de esas consultas para su examen por el Grupo de Trabajo en relación con i) las diversas opciones institucionales relativas a un registro; ii) la índole y el ámbito propuestos de un registro y las repercusiones conexas en materia de costos; y iii) las posibles repercusiones con respecto al proyecto de Reglamento.

2. Las instituciones arbitrales señalaron que la función de registro sería esencial para asegurar que se alcanzaran en la práctica los objetivos de transparencia. El

¹ El Centro Regional de Arbitraje Mercantil Internacional de El Cairo fue invitado a participar pero no pudo hacerlo.

Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si la determinación de la índole, la función, el alcance y los costos de un registro afectará necesariamente el nivel de transparencia que desde el punto de vista práctico logre el Reglamento en último término.

II. Establecimiento de un registro en el marco de proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado

A. Opciones institucionales para un registro

1. Opciones

3. Se proponen dos opciones para su examen en el marco del Reglamento (véase A/CN.9/WG.II/WP/176/Add.1, párr. 9) relativas a la posible administración institucional de un registro (véase también A/CN.9/736, párrs. 131 a 133; y A/CN.9/WG.II/WP.170, párrs. 7 y siguientes).

4. La primera opción (“opción 1”), consiste en un registro único para la publicación de información en el marco de las controversias entre inversionistas y Estados, de conformidad con un tratado, a que se aplique el Reglamento, cuyo mantenimiento estaría a cargo de una sola organización, mientras que otras instituciones arbitrales proporcionarían al registro visibilidad y asesoramiento cuando se les solicite, sin cumplir ninguna función relativa a su gestión cotidiana.

5. La segunda opción (“opción 2”) es un sistema mediante el cual diversas instituciones arbitrales mantendrían su propio sistema de registro. Esta opción podría presentar dos variantes: según la primera, todas las instituciones funcionarían con un sitio web común y una única interfaz para los usuarios exteriores. Una segunda variante de esa opción prevé que diversas instituciones arbitrales mantengan su propio sistema de registro, sin que exista una interfaz compartida para vincular a todos los registros entre sí, como en la primera variante, pero una organización tendría un sitio web que dispusiera de vínculos con cada procedimiento arbitral para los que se publique información en los registros en línea en las diversas instituciones.

2. Observaciones de las instituciones arbitrales sobre las opciones

6. La opción 1, expuesta en el párrafo 4 *supra*, recogió la preferencia más generalizada por varias razones.

7. En primer lugar, desde el punto de vista técnico, las instituciones consideraron que la opción 1 era la más atractiva. Según esta opción, sólo sería necesario crear un sistema técnico, un conjunto único de directrices técnicas que podría aplicarse fácilmente y ser mantenido de manera coherente, y no sería necesaria la gestión e integración técnica por una institución u organización “supervisora” si fallara un sistema como en el caso de haber registros múltiples. Un sistema único aseguraría una norma uniforme para la búsqueda de documentos, así como para la presentación de los resultados de la búsqueda. La gestión y la preservación de la seguridad de la información del registro serían más simples.

8. Con arreglo a la opción 2, la difusión de la publicación en varios sistemas de documentación institucionales no propiciaría la búsqueda a nivel mundial y, en consecuencia, en la práctica reduciría la transparencia. Se consideró que la variante 1 de la opción 2 era la más compleja desde el punto de vista técnico y muy probablemente técnicamente no viable. La variante 2 de la opción 2 se consideró en principio técnicamente viable, aunque un registro con un solo portal de Internet vinculado a varios sistemas subordinados requeriría un nivel adicional de supervisión sustantiva y la gestión por una sola organización, con el consiguiente aumento de costos y de complejidad.

9. Desde el punto de vista de los costos, las instituciones arbitrales subrayaron que, aparte de la CPA y el CIADI (cuyas distintas capacidades se indican más adelante en el párrafo 11), otras instituciones arbitrales no disponían de los sistemas técnicos o servidores necesarios, y el costo de su puesta en marcha, sumado a los gastos de mantenimiento y dotación de personal (para cualquier institución, incluidos la CPA y el CIADI) serían desproporcionadamente elevados en caso de que una institución recibiese sólo una fracción del número total de casos por año. Además, como las distintas instituciones seguramente deberán cobrar comisiones diferentes para sufragar sus respectivos gastos, la adopción de una estructura uniforme de comisiones para las instituciones supondría la adopción del mayor denominador común; de lo contrario, una estructura de honorarios no uniforme podría suscitar el desacuerdo entre las partes en una controversia sobre el registro institucional al que se recurriera.

10. Se dijo que la opción 2 requería un ámbito más claramente definido de las funciones de registro para que las instituciones arbitrales estuvieran dispuestas a comprometerse a asumirlas, a fin de que cada una pudiese evaluar los costos de actuar como registro en función de sus capacidades actuales o futuras, y ajustarlas a sus marcos presupuestarios².

11. Las actuales capacidades de las instituciones arbitrales consultadas son diferentes. Por ejemplo, el CIADI utiliza un sistema complejo de gestión de casos que está integrado con el sistema de gestión institucional de documentos del Banco Mundial. Este sistema incorpora un número seleccionado de metadatos para la búsqueda, y el proceso comprende un examen en distintos niveles de cada documento antes de su publicación. La CPA publica la información y los documentos de los casos con el acuerdo de las partes, pero no añade metadatos a esos documentos y actualmente no tiene un mecanismo de búsqueda que abarque la información de todos los casos públicos (ni tampoco la publicación de los documentos está vinculada a su sistema de gestión de documentos). Como la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio de Estocolmo, el LCIA y el CCI no publican información, para hacerlo deberían crear y administrar nuevos servidores o sistemas técnicos. Se consideró que, por lo menos algunas instituciones, o quizás todas ellas, necesitarían personal adicional para mantener una función de registro. En la CPA y el CIADI, instituciones que actualmente publican en alguna forma información relacionada con los casos, el personal asociado cuenta con un oficial

² En el documento A/CN.9/WG.II/WP.170 y su adición figuran las estimaciones de costos y las necesidades de personal de las instituciones arbitrales, a reserva de una definición más precisa de las funciones propuestas para el registro.

jurista (que cumple una función de examen), funcionarios de apoyo administrativo y tiempo dedicado por el personal de TI.

B. Naturaleza y alcance del registro

Nivel de transparencia y costos

12. Las instituciones arbitrales no pudieron proporcionar ninguna estimación global de los costos del registro, sin la orientación del Grupo de Trabajo en cuanto a sus funciones y su grado de perfeccionamiento deseables, porque los gastos tanto de puesta en marcha como de mantenimiento están estrechamente relacionados con la naturaleza de los sistemas establecidos y mantenidos.

13. Una base de datos única, con uniformidad de formato, función gratuita de búsqueda de textos y función de filtrado (que requiere la inserción por el registro de metadatos limitados; véase más adelante el párrafo 14) promovería un mayor nivel de transparencia (que admitiera en cierta medida investigaciones y análisis). También supondría un costo más elevado en comparación con un sistema en que los documentos simplemente se carguen en la web.

C. Cuestiones que podría tratar el Grupo de Trabajo

1. Alcance de las funciones de registro

14. El Grupo de Trabajo quizás desee examinar el alcance de la función de búsqueda deseable para un registro. A fin de dar al público el acceso más amplio posible a la información, entre los elementos de la función de búsqueda de los textos, además de ser completa y gratuita, podrían figurar: la inserción de metadatos para determinar el tipo de documento (que pueden corresponder a los tipos de documentos a que se refiere el proyecto de artículo 3 del Reglamento); el sector económico (que puede ser compatible con los identificadores de sectores del Banco Mundial); las partes; los abogados; los árbitros; el tratado a que corresponde la reclamación presentada; y las fechas.

15. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la conveniencia de incluir la posibilidad de que un tribunal arbitral proporcione al registro documentos en papel. Los documentos en papel plantean cuestiones particulares que deben tenerse en cuenta, como los recursos necesarios para su clasificación, almacenamiento y archivo, así como el posible requisito de que el registro cargue o escanee documentos en papel para que estén disponibles electrónicamente, al alcance de un público más amplio, así como cuestiones conexas como los costos y las cuestiones jurídicas relativas a la función de archivo. En particular, el Grupo de Trabajo quizás desee considerar en qué medida el almacenamiento por el registro de documentos en papel contribuiría a mejorar la transparencia, en caso de que los documentos solo pudieran obtenerse en una determinada ubicación física. Las instituciones arbitrales señalaron que tiende a prevalecer la norma que consiste en que se presenten todos los documentos a los tribunales en formato electrónico (aun cuando también puedan facilitarse en papel). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la conveniencia de que el Reglamento (o, si se considera apropiado, las directrices que lo acompañen, véase más adelante el párrafo 17) determine que el registro debería recibir

documentos e información solo en forma electrónica para evitar la labor de almacenamiento y archivo, que es costosa y requiere muchos recursos.

16. En un sistema de registro internacional, la traducción no sería factible, excepto en contextos muy limitados (por ejemplo, el nombre del tratado). La amplitud de la función de traducción y la correspondiente responsabilidad debería tenerse en cuenta en el propio Reglamento o en las directrices para los tribunales arbitrales (véase el párrafo 17 *infra*).

Directrices

17. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si serían necesarias directrices para los tribunales -incluidos requisitos sobre el formato de los documentos que se presenten al registro- y directrices para un registro -incluidas las directrices para la publicación y cuestiones relativas, por ejemplo, a la conservación digital, la seguridad, el idioma del sitio web y el margen de discrecionalidad del registro en diversos contextos, para que el sistema funcione debidamente.

2. Cuestiones para examinar en relación con el proyecto de reglamento

Proyecto de artículo 1 4) y proyecto de artículo 7 3)

18. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si el registro debería o deberá no revelar información o suprimir información ya publicada en caso de que se interponga una acción ante los tribunales nacionales, si estos tribunales consideran de carácter confidencial los documentos o la información proporcionada por el tribunal arbitral en el marco del Reglamento, con arreglo al derecho interno aplicable.

Proyecto de artículo 2

19. En el proyecto de artículo 2 se exige la publicación de determinada información (por ejemplo, el número de las partes, el sector económico y el tratado) antes de que haya sido constituido el tribunal arbitral. Las instituciones arbitrales sugirieron que, para reducir las posibilidades de que se proporcione información falsa o se presenten reclamaciones superfluas en esa etapa de las actuaciones y, por consiguiente, para limitar la responsabilidad de la institución que hace pública la información, debería modificarse el proyecto de artículo 2 para que incluyera:

a) El requisito de que se envíe a la otra parte en la controversia una copia de la información enviada al registro; y

b) Un procedimiento de objeción por la otra parte (por ejemplo, una objeción relativa a si se aplica el Reglamento sobre la Transparencia) dentro de un determinado plazo, en cuyo caso el registro esperaría para publicar la información correspondiente hasta que se constituyera el tribunal arbitral y se adoptara una decisión sobre cualquier objeción.

20. Se propuso además que el Reglamento debería incluir, en esta etapa inicial, anterior a la constitución, una disposición sobre un pago “por adelantado” (que habría de especificarse en detalle en un documento separado para facilitar las actualizaciones o enmiendas periódicas). Una propuesta era dar instrucciones al tribunal arbitral para que añadiese un porcentaje a su anticipo sobre los gastos. En términos más generales, el Grupo de Trabajo quizás desee examinar si se

determinará que en el Reglamento debería abordarse la cuestión de la inclusión de disposiciones relativas a lo que se pague al registro.

Proyecto de artículo 3

21. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la forma en que el registro atenderá las solicitudes de documentos una vez que el tribunal arbitral haya cumplido su función y su mandato se haya concluido. Las cuestiones resultantes de una solicitud posterior al procedimiento arbitral incluye, entre otros, el acceso a los documentos, decisiones relativas a restricciones y la determinación del carácter confidencial con arreglo al proyecto de artículo 7.

Proyecto de artículo 3 1)

22. El Grupo de Trabajo tal vez desee determinar si la publicación de “declaraciones o presentaciones por escrito” incluye la difusión de documentos tales como autos procesales, cartas o correos electrónicos.

Proyecto de artículo 3 2)

23. Con arreglo al proyecto de artículo 3 2), los informes de los peritos y las declaraciones de los testigos son proporcionadas por el tribunal al registro y se publican, en respuesta a solicitudes, y no están sujetas a ninguna decisión discrecional relativa a su publicación por el tribunal arbitral (a diferencia de los documentos a que se refiere el proyecto de artículo 3 3)). Esta disposición plantea las siguientes interrogantes:

a) ¿Cómo debería el registro atender una solicitud formulada después de que el tribunal haya cumplido sus funciones y se haya concluido su mandato? (véase el párrafo 21 *supra*).

b) Habida cuenta de que esos documentos pueden requerir revisión, y que esta puede ser controvertida y estar sujeta a una decisión definitiva del tribunal, ¿qué sucedería si el tribunal aún estuviera en funciones pero la solicitud se efectuara, por ejemplo, en una etapa avanzada de las actuaciones (por ejemplo, apenas antes de que se dicte el laudo definitivo) cuando las partes ya no estuvieran en condiciones de dedicar tiempo a la expurgación del texto o el tribunal, de hacer una determinación relativa a la expurgación?

c) A la luz de lo que precede, ¿es la intención que las partes deban proporcionar al tribunal informes de peritos y declaraciones de testigos (y, en consecuencia, el tribunal al registro) en forma expurgada, de manera de que estén disponibles cuando sean solicitados de conformidad con el proyecto de artículo 3 2), a fin de que corran por cuenta de las partes y del tribunal los gastos de la publicación de esos documentos, si bien quizás nunca se soliciten ni publiquen?

Proyecto de artículo 3 5)

24. Conforme a la propuesta de que todo almacenamiento y archivo de documentos en papel podría ser una carga inaceptable para un registro de la información publicada en las controversias de los Estados con inversionistas extranjeros (véase el párrafo 15 *supra*), el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la conveniencia de modificar o suprimir en el proyecto de artículo 3 5), las palabras

“fotocopiado o envío”, o quizás de reemplazarlas por las palabras “en que incurra el registro”, para conservar el significado actual.

Proyecto de artículo 8, opción 2

25. En el caso de que se escoja la opción 2, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la posibilidad de incluir un texto que indique cómo debe seleccionarse una institución y, en particular, en caso de que el demandado no designe una institución enumerada en el anexo.

Inclusión de una cláusula de exención de responsabilidad

26. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si debería añadirse al Reglamento una cláusula de exención de responsabilidad, con respecto tanto del tribunal arbitral, a través del cual se enviarán los documentos al registro con arreglo al artículo 3, como del propio registro. Tal vez el Grupo de Trabajo también debería examinar la cuestión de cómo abordar las reclamaciones de responsabilidad presentadas por terceros (por ejemplo, en caso de violación de la privacidad de los datos).

**H. Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales:
Guía de la CNUDMI relativa a la Convención sobre el Reconocimiento
y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras
(Nueva York, 1958): Extracto de la guía sobre el artículo VII**

(A/CN.9/786)

[Original: inglés]

1. En su 41º período de sesiones, celebrado en 2008, la Comisión convino en que era preciso iniciar trabajos para eliminar o limitar los efectos de la falta de armonía jurídica en cuanto a la interpretación y aplicación de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) (“la Convención”). La Comisión pidió a la Secretaría que estudiara si sería viable preparar una guía sobre la Convención, con miras a lograr una interpretación y aplicación uniformes de la Convención, lo que eliminaría la incertidumbre resultante de una aplicación parcial o imperfecta de su texto y reduciría el riesgo de que las prácticas de los Estados se apartaran del espíritu de la Convención. También en ese período de sesiones, la Comisión convino en que, en la medida en que lo permitieran los recursos, las actividades que realizaba la Secretaría en el contexto de su programa de asistencia técnica podrían incluir la difusión de información sobre la interpretación judicial de la Convención de Nueva York, lo cual sería de utilidad para complementar otras actividades realizadas en apoyo de dicha Convención¹. En sus períodos de sesiones 44º y 45º, celebrados en 2011 y 2012, se informó a la Comisión de que la Secretaría estaba llevando a cabo un proyecto relacionado con la preparación de una guía relativa a la Convención, en estrecha cooperación con el Señor G. Bermann (Columbia University School of Law) y el Señor E. Gaillard (Sciences Po School of Law), que habían formado equipos de investigación para trabajar en el proyecto. Se informó a la Comisión de que se había establecido un sitio web (www.newyorkconvention1958.org) a fin de hacer públicamente accesible la información reunida para la guía sobre la Convención de Nueva York². El anexo del presente documento contiene un extracto de la guía relativa a la Convención de Nueva York para su examen por la Comisión. Esta tal vez desee observar que, si lo permiten los recursos, la guía debería quedar terminada en diciembre de 2013.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/63/17 y Corr.1), párrs. 355 y 360.*

² *Ibid., sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 252; e *ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 135.*

Anexo: Guía de la CNUDMI relativa a la Convención de Nueva York

Extracto: artículo VII de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)

Artículo VII

1. *Las disposiciones de la presente Convención no afectarán la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales concertadas por los Estados Contratantes ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque.*

2. *El Protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las cláusulas de arbitraje y la Convención de Ginebra de 1927 sobre la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras dejarán de surtir efectos entre los Estados Contratantes a partir del momento y en la medida en que la presente Convención tenga fuerza obligatoria para ellos.*

LABOR PREPARATORIA SOBRE EL ARTÍCULO VII

La labor preparatoria sobre el artículo VII se describe en los siguientes documentos:

Proyecto de Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras y observaciones de gobiernos y organizaciones:

- Informe del Comité Especial sobre la ejecución de sentencias arbitrales internacionales: E/2704 y anexo.
- Observaciones de gobiernos y organizaciones sobre el proyecto de Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras: E/2822, anexos I y II; E/2822/Add.1, anexo I.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre arbitraje comercial internacional:

- Enmiendas al proyecto de Convención presentadas por delegaciones nacionales: E/Conf. 26/7; E/Conf. 26/L.16; E/Conf. 26/L.44.

Actas resumidas:

- Actas resumidas de las sesiones 18ª, 19ª y 20ª de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre arbitraje comercial internacional: E/CONF.26/SR.18; E/CONF.26/SR.19; E/CONF.26/SR.20.
- Acta resumida de la octava sesión del Comité Especial sobre la ejecución de sentencias arbitrales internacionales: E/AC.42/SR.8. Véase también E/AC.42/4/Rev.1.

(Pueden consultarse en el sitio web www.uncitral.org).

ARTÍCULO VII 1)

INTRODUCCIÓN

1. El artículo VII 1), que rige la relación de la Convención de Nueva York con otros tratados y la legislación nacional, se considera una de las piedras angulares de la Convención¹. Al establecer que la Convención no afectará la validez de otros tratados relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales, y al facilitar la aplicación de normas sobre el reconocimiento y la ejecución que puedan ser más liberales que las de la Convención, el artículo VII 1) garantiza la compatibilidad de la Convención con otros instrumentos internacionales así como su durabilidad, con el resultado de que las sentencias arbitrales extranjeras se reconocen y se ejecutan en la mayor medida posible.
2. En virtud del artículo VII 1), los Estados Contratantes no contravendrán la Convención cuando ejecuten sentencias arbitrales de conformidad con las disposiciones de leyes nacionales o tratados que sean más favorables para la ejecución. Esto refleja el concepto de que la Convención de Nueva York establece un límite, es decir, el máximo nivel de control, que los tribunales nacionales de los Estados Contratantes pueden ejercer sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales².
3. El artículo VII 1) está basado en el texto del artículo 5 de la Convención internacional para la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras (hecha en Ginebra el 26 de septiembre de 1927) (la “Convención de Ginebra”). El artículo 5 de la Convención de Ginebra otorgaba a una parte interesada el derecho de hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del Estado donde se invocara dicha sentencia³.
4. Los autores de la Convención de Nueva York ampliaron el alcance del artículo V de la Convención de Ginebra al agregar la norma de que las disposiciones de la Convención no afectarían la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales concertados por los Estados Contratantes⁴. La primera parte del artículo VII 1) se conoce por el nombre de “disposición de la compatibilidad”. La segunda parte del artículo VII 1), que permite a cualquier parte interesada hacer valer un tratado o una ley nacional

¹ Un comentarista dijo de esta disposición que era “un tesoro, una ingeniosa idea” de la Convención de Nueva York. Véase Philippe Fouchard, *Suggestions pour accroître l'efficacité internationale des sentences arbitrales*, 1998 REV. ARB. 653, en 663.

² Véase Philippe Fouchard, *La portée internationale de l'annulation de la sentence arbitrale dans le pays d'origine*, 1997 REV. ARB. 329; Emmanuel Gaillard, *Enforcement of Awards Set Aside in the Country of Origin: The French Experience*, en IMPROVING THE EFFICIENCY OF ARBITRATION AGREEMENTS AND AWARDS: 40 YEARS OF APPLICATION OF THE NEW YORK CONVENTION (A. J. van den Berg ed., 1999); Emmanuel Gaillard, *The Urgency of Not Revising the New York Convention*, en ICCA CONGRESS SERIES NO. 14, 50 YEARS OF THE NEW YORK CONVENTION: ICCA INTERNATIONAL ARBITRATION CONFERENCE 689 (A. J. van den Berg ed., 2009).

³ Para la historia legislativa del artículo VII 1) de la Convención de Nueva York y el artículo V de la Convención de Ginebra de 1927, véase Gerald H. Pointon, *The Origins of Article VII.1 of the New York Convention 1958*, en LIBER AMICORUM EN L'HONNEUR DE SERGE LAZAREFF 499 (L. Lévy, Y. Derains eds., 2011).

⁴ Labor preparatoria, Informe del Comité Especial sobre la ejecución de sentencias arbitrales internacionales, E/AC.42/4/Rev.1, pág. 15.

más favorables sobre el reconocimiento o la ejecución en lugar de la Convención, se conoce generalmente por el nombre de la disposición del “derecho más favorable”⁵.

5. Si bien puede resultar útil para ciertos fines analíticos dividir el párrafo en dos partes, el artículo VII 1), cuando se toma en su conjunto, consagra la idea del “derecho más favorable”. La primera parte del artículo VII 1) es solo la precursora de la segunda parte, que confirma que la validez de otros tratados no se verá afectada por la Convención, de modo que cualquier parte interesada podrá hacerlos valer si son más favorables. De este modo, el artículo VII 1) garantiza que en cualquier caso en que la Convención de Nueva York resulte menos favorable que las disposiciones de otro tratado o ley del país donde una parte trate de obtener el reconocimiento o la ejecución haciendo “valer una sentencia arbitral”, las normas más favorables tendrán primacía sobre las normas de la Convención de Nueva York.

ANÁLISIS

A. Principios generales

a. Significado de “partes interesadas”

6. El artículo VII 1) establece que las disposiciones de la Convención de Nueva York no privarán a “ninguna de las partes interesadas” de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer disposiciones más favorables del derecho interno o de un tratado.

7. Un tribunal suizo ha confirmado que la expresión “ninguna de las partes interesadas” se refiere solo a la parte que procura obtener la ejecución de una sentencia arbitral y no a la parte que se opone a dicha ejecución⁶. En un caso en que una parte italiana procuró obtener la ejecución de una sentencia arbitral contra una parte suiza, el tribunal de primera instancia de Zúrich rechazó el argumento de la parte suiza de que, en virtud del artículo VII 1), tenía derecho a hacer valer las condiciones más estrictas del Tratado bilateral entre Suiza e Italia sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias de 1933, para oponerse a la ejecución de la sentencia arbitral. Según el tribunal “el principio del derecho más favorable no ofrece a la parte que se opone a la ejecución otras causales para resistirse fuera de las enumeradas en la Convención”.

8. Como han observado los principales comentaristas, si se permite a la parte demandada hacer valer condiciones más estrictas de otra ley o tratado ello iría en contra del espíritu favorable a la ejecución de la Convención de Nueva York⁷.

⁵ ALBERT JAN VAN DEN BERG, THE NEW YORK ARBITRATION CONVENTION OF 1958: TOWARDS A UNIFORM JUDICIAL INTERPRETATION (1981), pág. 81; Emmanuel Gaillard, *The Relationship of the New York Convention with other Treaties and with Domestic Law*, en ENFORCEMENT OF ARBITRATION AGREEMENTS AND INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS: THE NEW YORK CONVENTION IN PRACTICE (E. Gaillard, D. Di Pietro eds., 2008), pág. 70.

⁶ *Italian party v. Swiss company*, Bezirksgericht, Zúrich, Suiza, 14 de febrero de 2003.

⁷ ALBERT JAN VAN DEN BERG, THE NEW YORK ARBITRATION CONVENTION OF 1958: TOWARDS A UNIFORM JUDICIAL INTERPRETATION (1981), págs. 333 y 334; Emmanuel Gaillard, *The Relationship of the New York Convention with other Treaties and with Domestic Law*, in ENFORCEMENT OF ARBITRATION AGREEMENTS AND INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS: THE NEW YORK CONVENTION IN PRACTICE (E. Gaillard, D. Di Pietro eds., 2008), págs. 74 y 75.

9. Según la labor preparatoria de la Convención de Nueva York, una de las “partes interesadas” puede también ser un Estado Contratante. Durante la negociación de la Convención, las delegaciones de los Estados consideraron que el prever expresamente esta situación sería superfluo puesto que ello se desprendía evidentemente del propio texto del artículo VII 1)⁸. Sin embargo, en la fecha de preparación de la presente guía no existía en la jurisprudencia ningún caso públicamente disponible en que un Estado hubiera invocado el artículo VII 1).

b. Contenido del derecho más favorable

10. El artículo VII 1) habla de “cualquier derecho”, sin ninguna restricción, admitido por la legislación o los tratados del país donde se invoque la sentencia. El Tribunal Federal alemán (*Bundesgerichtshof*) ha confirmado que, en la aplicación del artículo VII 1), un tribunal puede tener en cuenta las normas sobre el conflicto de leyes del derecho interno, lo cual puede dar por resultado la aplicación de una ley extranjera más favorable al reconocimiento y la ejecución que la Convención de Nueva York⁹.

c. No es necesaria la petición de parte

11. El artículo VII 1) establece que la Convención no privará a “ninguna de las partes interesadas” de cualquier derecho a “hacer valer” una sentencia arbitral.

12. La mayoría de los tribunales han adoptado el criterio de que una parte interesada no necesita pedir expresamente el reconocimiento o la ejecución invocando las leyes o los tratados más favorables a la ejecución¹⁰. Puesto que un tribunal no incurrirá en incumplimiento de la Convención de Nueva York si aplica normas más liberales en cuanto al reconocimiento y la ejecución, podrá invocar el artículo VII 1) de oficio. Por consiguiente, el Tribunal de Casación francés ha declarado que “el juez no puede denegar la ejecución cuando su propio ordenamiento nacional la permite y (...), en tal caso, debería investigar el asunto incluso de oficio”¹¹.

⁸ Labor preparatoria, Informe del Comité Especial sobre la ejecución de sentencias arbitrales internacionales, E/AC.42/4/Rev.1, pág. 15.

⁹ Bundesgerichtshof, Alemania, III ZB 18/05, 21 de septiembre de 2005, SchiedsVZ 2005, 306, en que la aplicación de las normas alemanas sobre el conflicto de leyes al artículo VII 1) de la Convención llevó al tribunal a aplicar el derecho neerlandés, que contenía requisitos formales más liberales para concertar un acuerdo de arbitraje que los del artículo II de la Convención.

¹⁰ *Société Pabalk Ticaret Sirketi v. Société Anonyme Norsolor*, Tribunal de Casación, Francia, 83-11.355, 9 de octubre de 1984; traducido al inglés en 24 ILM 360 (1985). Los tribunales alemanes siguen el mismo criterio. Véase Bundergerichtshof, Alemania, III ZB 50/05, 23 de febrero de 2006, SchiedsVZ 2006, 161. El Tribunal Supremo Federal suizo se ha apartado de este criterio sin dar sus razones. *Sudan Oil Seeds Co. Ltd. (U.K.) v. Tracom S.A. (Suiza)*. Tribunal Supremo Federal, Suiza, 5 de noviembre de 1985, Arrêts du Tribunal Fédéral (1985) 111 Ib 253.

¹¹ *Société Pabalk Ticaret Sirketi v. Société Anonyme Norsolor*, Tribunal de Casación, Francia, 83-11.355, 9 de octubre de 1984; traducido al inglés en 24 ILM 360 (1985), pág. 363.

d. Posibilidad de invocar múltiples regímenes ejecutorios

13. En ciertas decisiones, los tribunales alemanes han considerado que una parte que procure invocar otro tratado o ley nacional en virtud del artículo VII 1) debe hacerlo en su totalidad, con exclusión de la Convención de Nueva York¹². Según estas decisiones, no está permitido que una parte fundamente una petición de ejecución en la Convención y, al mismo tiempo, haga valer los requisitos formales más liberales de un acuerdo de arbitraje con arreglo al derecho alemán.

14. Otros tribunales alemanes han opinado, en cambio¹³, que el sesgo favorable de la Convención a la ejecución debería permitir a una parte interesada escoger las normas más favorables y combinarlas con las disposiciones de la Convención de Nueva York¹⁴. Un Tribunal Superior regional ordenó ejecutar una sentencia arbitral ateniéndose a los requisitos del derecho interno alemán, que son más favorables que los del artículo IV de la Convención, y aplicó, al mismo tiempo, el artículo V de la Convención con respecto a los posibles motivos para denegar la ejecución¹⁵. Un tribunal de los Estados Unidos también ordenó la ejecución de un laudo arbitral extranjero combinando elementos de la Convención de Nueva York con elementos más favorables del derecho interno¹⁶.

15. Además, tal como se indica en el párrafo 17 *infra*, el Tribunal Supremo Federal suizo ha sostenido que en caso de que sean aplicables a la ejecución de un laudo arbitral disposiciones jurídicas contradictorias en cuanto al reconocimiento y la ejecución, debe darse primacía a “la disposición que facilite dicho reconocimiento y dicha ejecución”, aceptando así, de manera implícita, una aplicación combinada de los dos regímenes¹⁷.

B. Interacción de la Convención con otros tratados

16. Ciertos laudos o acuerdos arbitrales pueden estar comprendidos no solo en el ámbito de aplicación de la Convención de Nueva York sino también en el de un tratado multilateral o bilateral. El artículo VII 1) establece la norma básica de la Convención de que esta no afectará la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los Estados Contratantes de la Convención y que una parte

¹² Bundesgerichtshof, Alemania, III ZB 18/05, 21 de septiembre de 2005; Bundesgerichtshof, Alemania, III ZB 50/05, 23 de febrero de 2006; Bundesgerichtshof, Alemania, III ZB 68/02, 25 de septiembre de 2003. Véase también Albert Jan van den Berg, *The German Arbitration Act 1998 and the New York Convention 1958*, in LIBER AMICORUM KARL-HEINZ BOCKSTIEGEL (Robert Briner et al. eds., 2001).

¹³ Por ejemplo, Oberlandesgericht de Celle, 8 Sch 06/06, 31 de mayo de 2007; Oberlandesgericht de Karlsruhe, 9 Sch 02/07, 14 de septiembre de 2007; Oberlandesgericht de Colonia, Alemania, 9 Sch 01-03, 23 de abril de 2004; Oberlandesgericht de Múnich, Alemania, 34 Sch 31/06, 23 de febrero de 2007.

¹⁴ JULIAN LEW AND LOUKAS A. MISTELIS, *COMPARATIVE INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION*, págs. 697 y 698 (2003); FOUCHARD GAILLARD GOLDMAN ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION, pág. 350 (E. Gaillard, J. Savage eds., 1996).

¹⁵ Oberlandesgericht de Colonia, Alemania, 9 Sch 01-03, 23 de abril de 2004.

¹⁶ *Chromalloy Aeroservices Inc. v. Ministry of Defence of the Republic of Egypt*, 939 F. Supp. 907 (D.D.C.1996).

¹⁷ *Denysiana S.A. v. Jassica S.A.*, Tribunal Supremo Federal, Suiza, 14 de marzo de 1984, Arrêts du Tribunal Fédéral 110 Ib 191, 194.

interesada podrá invocar esos tratados si son más favorables a la ejecución que la Convención. Esto está de acuerdo con el objetivo más amplio de la Convención de Nueva York de permitir en lo posible el reconocimiento y la ejecución de los laudos y acuerdos arbitrales, sea en virtud de sus propias disposiciones o las de otro instrumento.

17. Como lo ha confirmado el Tribunal Supremo Federal suizo, el artículo VII 1) deja sin efecto, de este modo, las reglas que normalmente rigen la aplicación de las disposiciones contradictorias de los tratados, a saber, que una norma jurídica posterior tiene primacía sobre una norma jurídica anterior (“*lex posterior derogat legi priori*”) y que, cuando dos o más normas se refieren al mismo tema, debe darse prioridad a la norma que sea más específica (“*lex specialis derogat legi generali*”). Como lo explicó el Tribunal, la Convención reemplaza esas normas con el principio de la máxima eficacia (“*règle d’efficacité maximale*”) al establecer que el instrumento que ha de tener primacía no es ni el más reciente ni el más específico, sino, en cambio, el que resulte más favorable para la ejecución de la sentencia arbitral extranjera. Dijo el Tribunal: “esta solución corresponde a la llamada regla de la máxima eficacia (...). Según esta regla, en caso de discrepancias entre las disposiciones de convenciones internacionales relativas al reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales, se dará preferencia a la disposición que permita o facilite dicho reconocimiento y dicha ejecución, ya sea por contener requisitos de fondo más liberales o por prever un procedimiento más simple. Esta norma está en consonancia con el objetivo de las convenciones bilaterales o multilaterales en la materia, que consiste en facilitar, en la medida de lo posible, el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales”¹⁸.

18. Si bien es cierto que las disposiciones de la Convención de Nueva York rara vez están en contradicción con las de otros instrumentos internacionales en cuanto al reconocimiento y la ejecución, en los casos en que los tribunales se han visto frente a un conflicto lo han resuelto, generalmente, guiándose por el criterio del derecho más favorable en virtud del artículo VII 1).

a. Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1961

19. El Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional (hecho en Ginebra, el 21 de abril de 1961) (el “Convenio Europeo”) es uno de los pocos instrumentos regionales que contienen normas más liberales sobre el proceso de arbitraje que la Convención de Nueva York. Es este el primer instrumento internacional que se ocupa del arbitraje internacional en su conjunto y, por consiguiente, establece normas que rigen todas sus diversas etapas. En la fecha de

¹⁸ *Denysiana S.A. v. Jassica S.A.*, Tribunal Supremo Federal, Suiza, 14 de marzo de 1984, Arrêts du Tribunal Fédéral 110 Ib 191, 194. Los tribunales de España también se han adherido a la opinión de que el artículo VII 1) sigue el principio de la máxima eficacia. Véase *Activial Internacional S.A. v. Conservas El Pilar S.A.*, Tribunal Supremo, España, 16 de abril de 1996, 3868/1992; *Unión de Cooperativas Agrícolas Epis-Centre v. La Palentina S.A.*, Tribunal Supremo, España, 17 de febrero de 1998, 3587/1996, 2977/1996; *Delta Cereales España S.L. v. Barredo Hermanos S.A.*, Tribunal Supremo, España, 6 de octubre de 1998.

preparación de la presente guía, son 32 los Estados que se han obligado a cumplir el Convenio Europeo¹⁹.

20. En el Convenio Europeo, el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales se consideran solo de manera muy indirecta²⁰. En consecuencia, en los casos en que un acuerdo o laudo arbitral se encuentra dentro del ámbito de aplicación tanto del Convenio Europeo como de la Convención de Nueva York, los tribunales han considerado acertadamente que las disposiciones de la Convención de Nueva York relativas a la ejecución complementan las disposiciones del Convenio Europeo y que no están obligados a aplicar la disposición del derecho más favorable del artículo VII 1). Así, por ejemplo, al considerar una solicitud de ejecución de una sentencia arbitral extranjera, un tribunal español aplicó ambos instrumentos, observando que “el Convenio Europeo se refiere al derecho aplicable y a la competencia de las autoridades judiciales y árbitros, en tanto que la Convención de Nueva York se refiere al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales”²¹. Los tribunales alemanes han afirmado el carácter complementario de estos instrumentos remitiéndose al artículo 106 (1) del Código de Procedimiento Civil alemán, según el cual las disposiciones de otros tratados relativos al reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales no se verán afectadas por la aplicación de la Convención de Nueva York²².

b. Convención de Panamá de 1975

21. La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (hecha en Panamá el 30 de enero de 1975) (la “Convención de Panamá”) se elaboró tomando por modelo la Convención de Nueva York y se redactó en términos

¹⁹ Para el estado actual del Convenio Europeo, véase United Nations Treaty Collection, en http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-2&chapter=22&lang=en.

²⁰ En virtud del artículo I, el Convenio Europeo es aplicable a “los acuerdos de arbitraje concertados para resolver controversias de comercio internacional entre personas físicas o jurídicas que, en el momento de concertarse el acuerdo, tuvieran su residencia habitual o su domicilio o sede social en Estados contratantes diferentes” y a los “procedimientos y laudos arbitrales basados en” tales acuerdos. Su aplicación difiere, pues, de la Convención de Nueva York en dos aspectos: i) el Convenio Europeo es aplicable solamente a las controversias surgidas en operaciones de comercio internacional; y ii) el Convenio Europeo impone la condición de que las partes en el acuerdo de arbitraje procedan de distintos Estados contratantes. El ámbito de aplicación de la Convención de Nueva York no está limitado por ninguna de estas dos condiciones y, por tanto, es más amplio.

²¹ *Nobulk Cargo Services Ltd. v. Compañía Española de Laminación S.A.*, Tribunal Supremo, España, 27 de febrero de 1991. Véase también la misma opinión expresada por tribunales franceses en *Société Européenne d'Etudes et d'Entreprises (S.E.E.E.) v. République Socialiste Fédérale de Yougoslavie*, Tribunal de Apelaciones de Ruán, Francia, 13 de noviembre de 1984.

²² Véase, por ejemplo, *Oberlandesgericht de Múnich, Alemania*, 34 Sch 019/08, 27 de febrero de 2009. En los casos, en cambio, en que una parte que se resiste a la ejecución haya aducido que una parte interesada no puede invocar al mismo tiempo el Convenio Europeo y la Convención de Nueva York en apoyo de su petición de ejecución, un tribunal italiano se remitió a la compatibilidad consagrada en la primera oración del artículo VII 1) para fundamentar su conclusión de que los dos instrumentos serían aplicables. Véase *Arenco-BMD Maschinenfabrik GmbH v. Società Ceramica Italiana Pozzi-Richard Ginori S.p.A.*, Corte di Appello de Milán, Italia, 16 de marzo de 1984.

plenamente compatibles con esta²³. La Convención de Panamá contiene disposiciones relativas al reconocimiento y la ejecución de laudos que son similares, pero no idénticas, a las que contiene la Convención de Nueva York²⁴. En la fecha de preparación de la presente guía, la Convención de Panamá era aplicable en 19 países, todos los cuales eran también Partes Contratantes de la Convención de Nueva York²⁵.

22. Según un estudio realizado en 2008 sobre las decisiones adoptadas en América Latina, la mayoría de los Estados latinoamericanos que son partes en ambos instrumentos han invocado exclusivamente la Convención de Nueva York en los casos de reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras²⁶.

23. La mayoría de los casos en los cuales, según se informa, se examinó la Convención de Panamá, se plantearon en los Estados Unidos de América, cuya Ley federal de arbitraje contiene disposiciones que rigen la relación entre la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá. El artículo 305 de la Ley federal de arbitraje establece que cuando ambas Convenciones son aplicables a un laudo o acuerdo arbitral, se aplicará la Convención de Panamá si la mayoría de las partes en el acuerdo de arbitraje son ciudadanas de un Estado o Estados que hayan ratificado la Convención de Panamá o se hayan adherido a esta y sean Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Al mismo tiempo, el artículo 302 de la Ley federal de arbitraje establece el carácter obligatorio de la aplicación de ciertas disposiciones de la Ley federal de arbitraje junto con las disposiciones de la Convención de Panamá²⁷.

24. En la práctica, los tribunales de los Estados Unidos de América han aplicado la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá como si fueran idénticas. Por ejemplo, en un caso planteado ante un tribunal de distrito de los Estados Unidos, en que una de las partes procuró obtener la ejecución de un laudo invocando al mismo tiempo la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá, el tribunal limitó su consideración a la Convención de Nueva York aduciendo que “la codificación de la Convención de Panamá incorpora, por

²³ Albert Jan van den Berg, *The New York Convention 1958 and the Panama Convention of 1975: Redundancy or Compatibility?*, 5 ARB. INTL. 214 (1989).

²⁴ Así, por ejemplo, a diferencia del artículo II 3) de la Convención de Nueva York, la Convención de Panamá no contiene ninguna disposición que establezca específicamente que los tribunales de un Estado contratante estén obligados a remitir a las partes al arbitraje cuando se les haya sometido un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo de arbitraje comprendido en su ámbito de aplicación. Si bien es cierto que el artículo 5 de la Convención de Panamá incorpora en gran medida los motivos de denegación previstos en el artículo V de la Convención de Nueva York, la redacción concreta de estos artículos difiere en varios aspectos. Además, a diferencia de la Convención de Nueva York, la Convención de Panamá contiene disposiciones que rigen otros aspectos del arbitraje, como el nombramiento de árbitros (artículo 2), y las reglas de procedimiento del arbitraje (artículo 3).

²⁵ Puede consultarse el estado actual de la Convención de Panamá en: www.oas.org/juridico/english/sigs/b-35.html.

²⁶ Cristián Conejero Roos, *The New York Convention in Latin America: Lessons From Recent Court Decisions*, en 2009, GLOBAL ARBITRATION REVIEW, THE ARBITRATION REVIEW OF THE AMERICAS 21.

²⁷ Código de los Estados Unidos, título 9 - arbitraje, § 302, que especifica:

“Los artículos 202, 203, 204, 205 y 207 del presente título serán aplicables al presente capítulo como si ello estuviera expresamente previsto en él, salvo que para los fines del presente capítulo “la Convención” significa la Convención Interamericana”.

remisión, las disposiciones pertinentes de la Convención de Nueva York (...), lo que vuelve superfluo el examen de la Convención de Panamá”²⁸.

25. El efecto del artículo VII 1) en los casos en que son aplicables tanto la Convención de Nueva York como la Convención de Panamá no se ha examinado en la jurisprudencia. Sin embargo, en algunos casos concretos, la Convención de Panamá puede ofrecer mejores opciones de ejecución en comparación con las ofrecidas por la Convención de Nueva York. Así, por ejemplo, el artículo 4 de la Convención de Panamá puede, en ciertos casos, ofrecer opciones más favorables para la ejecución de sentencias arbitrales que la Convención de Nueva York al equiparar las sentencias arbitrales definitivas con los fallos judiciales definitivos²⁹. Acogiéndose a la disposición del derecho más favorable de la Convención de Nueva York, una parte que procurase obtener la ejecución de un laudo comprendido dentro del ámbito de ambos instrumentos podría aprovechar esta opción.

c. *Tratados bilaterales*

26. De conformidad con el artículo VII 1), una parte interesada puede fundamentar su petición de ejecución en un acuerdo bilateral que trate específicamente del reconocimiento y la ejecución de laudos y acuerdos arbitrales extranjeros, y también en acuerdos bilaterales que contengan, entre otras cosas, disposiciones sobre estos temas³⁰. Las condiciones para el reconocimiento y la ejecución con arreglo a acuerdos bilaterales puede ser más o menos favorable que la Convención de Nueva York, según las circunstancias del laudo.

27. Cabe citar, a manera de ejemplo, la práctica de los tribunales alemanes, que han aplicado disposiciones más favorables de tratados bilaterales de conformidad con el artículo VII 1). En un caso planteado ante el Tribunal Federal alemán, se permitió que una parte interesada invocara el Tratado belga-alemán de 1958 relativo al reconocimiento y la ejecución recíprocos de decisiones judiciales, laudos arbitrales y documentos oficiales en asuntos civiles y comerciales, según el cual un laudo dictado en Bélgica debe reconocerse y ejecutarse en Alemania cuando haya

²⁸ *TermoRio S.A. E.S.P. v. Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P.*, Tribunal de distrito, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, 17 de marzo de 2006, 421 F. Supp. 2d 87, (D.D.C. 2006), nota de pie de página núm. 4, pág. 91. Véase también *Productos Mercantiles e Industriales, S.A. v. Faberge USA Inc.*, Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, segundo circuito, Estados Unidos de América, 18 de abril de 1994, 23 F.3d. 41 (segundo circuito, 1994), pág. 45, en que el Tribunal observó que “La historia legislativa de la ley de ejecución de la Convención Interamericana ... demuestra claramente que la intención del Congreso fue que la Convención Interamericana llevara a los mismos resultados que los obtenidos con la aplicación de la Convención de Nueva York”.

²⁹ El artículo 4 de la Convención de Panamá establece lo siguiente: “Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales”. Esta disposición reduce, no obstante, la igualdad de tratamiento entre los laudos arbitrales y los fallos judiciales al disponer que su ejecución o reconocimiento “podrá exigirse”, a diferencia del “reconocerá” del artículo III de la Convención de Nueva York.

³⁰ Franz Matscher, *Experience with Bilateral Treaties*, en ICCA CONGRESS SERIES NO. 9, IMPROVING THE EFFICIENCY OF ARBITRATION AGREEMENTS AND AWARDS: 40 YEARS OF APPLICATION OF THE NEW YORK CONVENTION 452 (A.J. van den Berg ed., 1999).

sido declarado ejecutable en Bélgica y no viole las normas alemanas de orden público³¹.

28. Los tribunales también han considerado la cuestión de si un tratado bilateral aplicable excluye específicamente la aplicación de la Convención de Nueva York y, cuando han concluido que no la excluye, han ejecutado los laudos con arreglo, o bien a la Convención de Nueva York, o a disposiciones más favorables del derecho interno. Por ejemplo, en una decisión de 1997 -*Chromalloy*- el Tribunal de Apelaciones de París examinó un argumento aducido por Egipto de que debía denegarse la ejecución del laudo, entre otras cosas, porque violaba el artículo 33 de la Convención Franco-Egipcia de 1982 sobre cooperación judicial (la “Convención franco-egipcia”)³². A juicio del tribunal, puesto que la Convención Franco-Egipcia establecía expresamente que el reconocimiento y la ejecución de los laudos debía otorgarse de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Nueva York, los Estados habían consentido tácitamente en la aplicación de cualquier disposición más favorable del derecho interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII 1). Al ejecutar el laudo, el Tribunal se basó en los motivos más limitados de denegación de la ejecución con arreglo al artículo 1502 aplicable del Código de Procedimiento Civil francés³³.

C. Interacción de la Convención con el derecho interno

29. El artículo VII 1) facilita el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras al asegurar que los Estados Contratantes no incurrirán en incumplimiento de la Convención si ejecutan laudos arbitrales en virtud de disposiciones más favorables contenidas en su legislación nacional.

30. Los Estados Contratantes de la Convención de Nueva York han adoptado en sus leyes nacionales toda una serie de enfoques del reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. En tanto que las leyes nacionales sobre arbitraje de algunas jurisdicciones disponen que el reconocimiento y la ejecución se han de regir por la Convención de Nueva York³⁴, otras contienen disposiciones expresas sobre el reconocimiento y la ejecución³⁵. Otras leyes disponen que un laudo

³¹ Bundesgerichtshof, Alemania, III ZR 78/76, 9 de marzo de 1978. Véase también Bundesgerichtshof, Alemania, III ZB 50/05, 23 de febrero de 2006, en que el Tribunal Federal Supremo devolvió las actuaciones al Oberlandesgericht de Karlsruhe, que, a su juicio, había considerado equivocadamente una petición de denegación de ejecución de un laudo dictado en Minsk en vista de las disposiciones de la Convención de Nueva York, en lugar de aplicar las condiciones más estrictas de no ejecución contenidas en el tratado bilateral de 1958 sobre cuestiones generales de comercio y navegación entre Alemania y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que sigue siendo aplicable con respecto a Belarús.

³² *République arabe d’Egypte v. Société Chromalloy Aero Services*, Tribunal de Apelaciones de París, Francia, 14 de enero de 1997.

³³ Para un ejemplo de razonamiento similar de los tribunales alemanes, véase Bundesgerichtshof, Alemania, XI ZR 349/89, 26 de febrero de 1991; Oberlandesgericht, Fráncfort, Alemania, 6 U (Kart) 115/88, 29 de junio de 1989; y, como ejemplo de un tribunal italiano, véase *Viceré Livio v. Prodexport*, Corte di Cassazione, 11 de julio de 1992.

³⁴ Por ejemplo, Suiza, Ley sobre derecho internacional privado, 1987, artículo 194; Alemania, Ley de arbitraje, 1998, artículo 1061.

³⁵ Por ejemplo, Francia, Nuevo Código de Procedimiento Civil, artículos 1504 a 1527; Países Bajos, Código de Procedimiento Civil, artículo 1076.

extranjero puede ejecutarse si un tribunal del país donde se dictó el laudo ha dictado sentencia sobre el laudo³⁶.

a. Casos en que el derecho interno es más favorable que el artículo II

31. El artículo VII 1) se refiere a la ejecución solo de las “sentencias arbitrales” y no de los “acuerdos de arbitraje”. Como han observado los comentaristas, la omisión de los acuerdos de arbitraje en el texto del artículo VII 1) no fue intencional³⁷ y puede explicarse por la inclusión de las disposiciones relativas a los acuerdos de arbitraje en la Convención de Nueva York en una etapa muy avanzada de las negociaciones³⁸.

32. Hace ya mucho tiempo que los tribunales franceses vienen considerando que el artículo VII 1) es aplicable también al reconocimiento y la ejecución de los acuerdos arbitrales. De este modo, en una serie de decisiones que se remontan a 1993, los tribunales franceses han sostenido que, con arreglo al artículo VII 1) de la Convención, los acuerdos de arbitraje pueden ejecutarse de conformidad con las disposiciones más favorables del derecho de arbitraje francés, y no con arreglo a los requisitos más estrictos del artículo II de la Convención de Nueva York³⁹.

33. Como confirmación de que el artículo VII 1) también es aplicable a los acuerdos de arbitraje, la CNUDMI aprobó, en su 39º período de sesiones, celebrado en 2006, una recomendación relativa a la interpretación de los artículos II 1) y VII 1) de la Convención de Nueva York. En la recomendación se aclara que el artículo VII 1) debe aplicarse “de forma que permita a toda parte interesada acogerse a los derechos que puedan corresponderle, en virtud de las leyes o tratados del país donde se invoque el acuerdo de arbitraje, para obtener el reconocimiento de la validez de ese acuerdo de arbitraje”⁴⁰.

³⁶ Por ejemplo, Italia, Código de Procedimiento Civil, artículo 830; Colombia, Código de Procedimiento Civil, Decreto Número 1400 y 2019 de 1970, artículo 694 3).

³⁷ ICCA’S GUIDE TO THE INTERPRETATION OF THE 1958 NEW YORK CONVENTION: A HANDBOOK FOR JUDGES (P. Sanders ed., 2011), pág. 27; ALBERT JAN VAN DEN BERG, THE NEW YORK ARBITRATION CONVENTION OF 1958: TOWARDS A UNIFORM JUDICIAL INTERPRETATION (1981), págs. 86 a 88.

³⁸ Labor preparatoria, Conferencia de las Naciones Unidas sobre arbitraje comercial internacional, acta resumida de la 16ª sesión, E/CONF.26/SR.16.

³⁹ Véase *Bomar Oil NV v. Etap – L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières*, Tribunal de Casación, Francia, 87-15.094, 9 de noviembre de 1993, 1994 REV. ARB. 108; *American Bureau of Shipping (ABS) v. Copropriété maritime Jules Verne*, Tribunal de Casación, 03-12.034, Francia, 7 de junio de 2006, 2006 REV. ARB. 945; *SA Groupama transports v Société MS Régine Hans und Klaus Heinrich KG*, Tribunal de Casación, Francia, 05-21.818, 21 de noviembre de 2006. El antiguo artículo 1443 del Código de Procedimiento Civil francés, en vigor desde 1981, disponía que un acuerdo de arbitraje se registraría por la convención principal o un documento al que se refiriese la convención, sin establecer más requisitos para la validez del acuerdo de arbitraje en asuntos de arbitraje internacional. El actual artículo 1507 del Código de Procedimiento Civil francés aplicable al arbitraje comercial internacional dispone que “los acuerdos de arbitraje no estarán sujetos a ningún requisito en cuanto a su forma”. En la fecha de preparación de la presente guía no se ha comunicado ningún caso en que un tribunal francés haya invocado esta disposición al aplicar el artículo VII 1) de la Convención.

⁴⁰ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/61/17), anexo II.*

34. Desde que la CNUDMI adoptó esa recomendación, los tribunales de varios Estados Contratantes han ejecutado, en aplicación del artículo VII 1), los acuerdos de arbitraje con arreglo a las leyes nacionales, siempre que impongan requisitos formales menos estrictos. Así, por ejemplo, en una decisión reciente, el Tribunal Federal alemán ejecutó una sentencia arbitral que afectaba a dos partes comerciales interesadas ateniéndose a la teoría de la *kaufmännisches Bestätigungsschreiben*, según la cual los contratos comerciales, incluidos los acuerdos de arbitraje, pueden concertarse por aceptación tácita de una carta de confirmación entre comerciantes⁴¹. De modo análogo, los tribunales neerlandeses han aplicado el artículo VII 1) para ejecutar laudos de conformidad con una disposición del derecho interno, según la cual el tribunal considerará, a petición de parte, que un acuerdo de arbitraje es válido aunque no esté incluido en el contrato firmado por las partes o figure en un intercambio de cartas o telegramas, condiciones que exige, por lo demás, el artículo II de la Convención de Nueva York⁴².

35. Las leyes nacionales de algunos otros ordenamientos jurídicos nacionales también contienen menos exigencias formales para la validez de un acuerdo de arbitraje que la Convención de Nueva York. Por ejemplo, la Ley sobre arbitraje internacional de Suiza dispone que un acuerdo de arbitraje será válido si se concierta “por escrito, telegrama, télex, telecopiadora o cualquier otro medio de comunicación que permita dejar una constancia escrita”⁴³. De manera aún más amplia, la ley sobre arbitraje del Reino Unido dispone explícitamente que no hay necesidad de que el texto escrito esté firmado por una de las partes y basta con que lo haya registrado una de las partes, o un tercero autorizado por las partes en el acuerdo⁴⁴. Una parte que procurase obtener la ejecución de un laudo arbitral podría invocar estas disposiciones de conformidad con el artículo VII 1) de la Convención.

b. Casos en que el derecho interno es más favorable que el artículo IV

36. El artículo IV de la Convención de Nueva York establece qué documentos debe presentar el demandante en el momento de formular la petición de reconocimiento o ejecución, o ambas cosas, a saber: el original debidamente autenticado de la sentencia o una copia que reúna las condiciones requeridas, el original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una copia que reúna las

⁴¹ Bundesgerichtshof, Alemania, III ZB 69/09, 30 de septiembre de 2010, SchiedsVZ 2010, 332. Véase también Kammergericht de Berlín, Alemania, 20 Sch 09/09, 20 de enero de 2011; Oberlandesgericht de Celle, Alemania, 8 Sch 14/05, 14 de diciembre de 2006.

Los tribunales alemanes ejecutaban los acuerdos de arbitraje con arreglo a este principio aun antes de adoptar la CNUDMI la recomendación de 2006. Véase Oberlandesgericht de Colonia, Alemania, 16 W 43/92, 16 de diciembre de 1992. El concepto, por lo que se refiere a los acuerdos de arbitraje, quedó codificado en 1998 en el artículo 1031 (2) del nuevo Código de Procedimiento Civil alemán, que se refleja en las normas relativas a los laudos internos. El Oberlandesgericht de Fráncfort ha considerado que el artículo VII 1) de la Convención, que se refiere a las leyes relativas a la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, no llevaría necesariamente a la aplicación del artículo 1031 (2). Véase Oberlandesgericht de Fráncfort, Alemania, 26 Sch 28/05, 26 de junio de 2006.

⁴² *Claimant v. Ocean International Marketing B.V., et al*, Rechtbank de Rotterdam, Países Bajos, 29 de julio de 2009, 194816/HA ZA 03-925.

⁴³ Suiza, Ley sobre derecho internacional privado, 1987, artículo 178 1).

⁴⁴ Reino Unido, ley sobre arbitraje de 1996, c. 23, artículo 5.

condiciones requeridas para su autenticidad y una traducción de estos documentos al idioma del país en que se invoca la sentencia, en su caso.

37. Los tribunales de Alemania han aplicado sistemáticamente el principio del derecho más favorable contenido en el artículo VII 1) a fin de que una parte interesada pueda invocar los requisitos menos exigentes del derecho alemán, en virtud del cual una parte que procure obtener la ejecución de una sentencia arbitral extranjera en Alemania solo necesita presentar el original autenticado de la sentencia o una copia autenticada⁴⁵.

38. De igual modo, los tribunales alemanes han aplicado las disposiciones más favorables del derecho interno para eximir del requisito impuesto en el artículo IV 2) de la Convención por el cual la parte interesada debe presentar la traducción de la sentencia arbitral y del acuerdo de arbitraje original⁴⁶. Los tribunales de Suiza han seguido el mismo criterio y han aplicado la disposición más favorable del artículo 193 1) de la Ley suiza sobre el derecho internacional privado⁴⁷.

c. Casos en que el derecho interno es más favorable que el artículo V 1) e)

39. En virtud del artículo VII 1) de la Convención de Nueva York, una parte interesada puede pedir la aplicación de una ley nacional si es más favorable que las disposiciones de la Convención, incluidos los motivos de denegación enumerados en el artículo V. Entre dichos motivos, el artículo V 1) e) establece que el reconocimiento y la ejecución pueden ser denegados si la sentencia “ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia”.

⁴⁵ Alemania, Código de Procedimiento Civil, artículos 1064 1) y 3). Véase, por ejemplo, Oberlandesgericht de Múnich, Alemania, 34 Sch 14/09, 1 de septiembre de 2009; Bundesgerichtshof, Alemania, III ZB 68/02, 25 de septiembre de 2003. Véase también Oberlandesgericht de Múnich, 22 de junio de 2009; Oberlandesgericht de Múnich, 34 Sch 19/08, 27 de febrero de 2009; Oberlandesgericht de Múnich, 34 Sch 18/08, 17 de diciembre de 2008; Oberlandesgericht de Fráncfort, 17 de octubre de 2007; Oberlandesgericht de Múnich, 23 de febrero de 2007; Oberlandesgericht de Celle, 14 de diciembre de 2006; Kammergericht, 10 de agosto de 2006; Oberlandesgericht de Múnich, 15 de marzo de 2006; Oberlandesgericht de Múnich, 28 de noviembre de 2005; Oberlandesgericht de Dresde, 7 de noviembre de 2005; Oberlandesgericht de Dresde, 2 de noviembre de 2005; Oberlandesgericht de Hamm, 27 de septiembre de 2005; Bayerisches Oberstes Landesgericht, 11 de agosto de 2000. Para la opinión contraria, véase Oberlandesgericht Rostock, Alemania, 1 Sch 03/00, 22 de noviembre de 2001, en que el tribunal consideró que el artículo VII 1) no podía invocarse para permitir a una parte que prescindiera de cumplir los requisitos formales para obtener la ejecución con arreglo a la Convención de Nueva York.

⁴⁶ Por ejemplo, Oberlandesgericht de Celle, Alemania, 8 Sch 14/05, 14 de diciembre de 2006; Kammergericht de Berlín, 20 Sch 07/04, 10 de agosto de 2006. Véase también Oberlandesgericht de Múnich, 28 de noviembre de 2005; Oberlandesgericht de Hamm, 27 de septiembre de 2005; Oberlandesgericht de Colonia, 23 de abril de 2004.

⁴⁷ Tribunal Supremo Federal, Suiza, 2 de julio de 2012, Decisión 5A_754/2011. Los tribunales de los Países Bajos también han ejecutado laudos de conformidad con el artículo 1076 del Código de Procedimiento Civil neerlandés, que es más favorable que el artículo IV de la Convención: *Dubai Drydocks v. Bureau voor Scheeps- en Werktuigbouw [X] B.V.*, Rechtbank, Dordrecht, Países Bajos, 30 de junio de 2010, 79684/KG RK 09-85.

40. En la historia legislativa de la Convención no hay nada que indique que se haya examinado la relación entre los artículos V 1) e) y VII 1). En particular, no consta en actas que las delegaciones de los Estados o sus gobiernos hayan considerado la posibilidad de que una sentencia anulada o suspendida pudiera ejecutarse invocando el artículo VII 1).

41. El texto definitivo de la Convención de Nueva York no prohíbe que un tribunal de un Estado Contratante reconozca o ejecute una sentencia en esas circunstancias si se puede reconocer o ejecutar en virtud del derecho interno del Estado u otro tratado en que sea parte. Al aplicar la disposición del derecho más favorable del artículo VII 1), los tribunales de ciertos Estados Contratantes han ejecutado de manera sistemática sentencias que habían sido anuladas o suspendidas.

42. Por ejemplo, en una serie de decisiones que se remontan a 1984, los tribunales franceses establecieron la norma de que una parte que impugne la ejecución no podrá hacerlo invocando los motivos previstos en el artículo V 1) e) de la Convención debido a que en el derecho francés esos motivos son más limitados⁴⁸. En el caso *Hilmarton*, de 1994, el Tribunal de Casación ejecutó un laudo dictado en Suiza pese al hecho de que había sido anulado por el Tribunal Supremo Federal suizo y se había constituido un nuevo tribunal de arbitraje para conocer de la controversia. El Tribunal razonó que “la sentencia arbitral dictada en Suiza es un laudo internacional que no está integrado en el ordenamiento jurídico de ese Estado, de manera que sigue existiendo aun cuando haya sido anulado, y su reconocimiento en Francia no es contrario al orden público”⁴⁹.

43. Los tribunales franceses se han guiado por este razonamiento en toda una serie de casos subsiguientes⁵⁰. En la decisión *Putrabali*, de 2007, por ejemplo, el Tribunal de Casación afirmó que “una sentencia arbitral internacional, que no se fundamente en ningún orden jurídico nacional, constituye una decisión de un sistema de justicia internacional cuya validez debe determinarse con respecto a las normas aplicables en el país donde se procura obtener su reconocimiento y ejecución. En virtud del artículo VII [la parte interesada] (...) podría invocar las

⁴⁸ El antiguo artículo 1502 de Código de Procedimiento Civil francés, en vigor hasta 2011, contenía una lista exhaustiva de las cinco causales que podían invocarse para denegar el reconocimiento y la ejecución en Francia. Véase *Société Pabalk Ticaret Sirketi v. Société Anonyme Norsolor*, Tribunal de Casación, Francia, 83-11.355, 9 de octubre de 1984, 1985 REV. ARB. 431; traducido al inglés en 24 ILM 360 (1985). Los artículos 1520 y 1525 (4) del Código de Procedimiento Civil francés actualmente en vigor prevé los mismos motivos de denegación.

⁴⁹ *Société OTV v. Société Hilmarton*, Tribunal de Casación, Francia, 10 de junio de 1997. XX Y.B. Com Arb. 663, en 665, párr. 5. El nuevo tribunal cuya constitución había ordenado el Tribunal Supremo Federal suizo dictó posteriormente una segunda sentencia contradictoria en que ordenaba al demandante que pagase un honorario de consulta en virtud del contrato del caso. El Tribunal de Casación francés revocó un fallo de un tribunal inferior que había reconocido la segunda sentencia, y sostuvo que en Francia se reconocía solo la primera sentencia, aduciendo que el reconocimiento en Francia del primer laudo, anulado fuera de Francia, impedía irrevocablemente el reconocimiento o la ejecución en Francia del segundo laudo.

⁵⁰ *Bargues Agro Industrie S.A. (France) v. Young Pecan Company (US)*, Tribunal de Apelaciones de París, Francia, 10 de junio de 2004, 2004 REV. ARB. 733; *PT Putrabali Adyamulia v. S.A. Rena Holding*, Tribunal de Apelaciones de París, Francia, 31 de marzo de 2005, 2006 REV. ARB. 665, afirmado por *PT Putrabali Adyamulia v. S.A. Rena Holding*, Tribunal de Casación, Francia, 05-18053, 29 de junio de 2007, 2007 REV. ARB. 507; *Direction Generale de l'Aviation Civile de l'Emiral de Dubai v. International Bechtel Co., LLP*, Tribunal de Apelaciones de París, Francia, 29 de septiembre de 2005, 2006 REV. ARB. 695.

normas francesas sobre arbitraje internacional, según las cuales la anulación de una sentencia en el país de origen no es motivo para denegar el reconocimiento y la ejecución de un laudo dictado en un país extranjero”⁵¹.

44. Ese mismo año, el Tribunal de Apelaciones de París llegó a la conclusión de que la norma según la cual la anulación de una sentencia arbitral en un país extranjero no afecta al derecho de la parte interesada de pedir la ejecución de la sentencia en Francia (puesto que el árbitro no forma parte del ordenamiento jurídico nacional del país donde se dictó la sentencia) constituye un “principio fundamental en virtud del derecho francés”⁵².

45. En la decisión *Chromalloy*, de 1996, el Tribunal Federal de los Estados Unidos del Distrito de Columbia siguió un criterio similar y dio curso a una solicitud de ejecución de un laudo dictado en Egipto y posteriormente anulado por un tribunal de apelaciones de Egipto⁵³. El Tribunal consideró que, a diferencia del artículo V de la Convención, que establece un “criterio facultativo”, en virtud del cual un tribunal “puede” denegar la ejecución de un laudo, el artículo VII 1) “obliga al tribunal a considerar la petición [de la parte interesada] con arreglo al derecho aplicable de los Estados Unidos”. El Tribunal examinó la cuestión de si las razones que había tenido el Tribunal egipcio para anular la sentencia eran motivos que podrían haber justificado la anulación de una sentencia nacional en virtud del artículo 10 de la Ley federal de arbitraje, capítulo 1. El Tribunal sostuvo que, puesto que la sentencia no habría sido anulada de conformidad con el artículo 10, debía ejecutar la sentencia en virtud del artículo VII 1) de la Convención.

46. Por otra parte, la Convención de Nueva York no obliga a los tribunales de los Estados Contratantes a reconocer una sentencia que haya sido anulada o suspendida y no incurrirán en incumplimiento de la Convención si se niegan a hacerlo.

47. Algunos tribunales han sostenido que la ejecución de una sentencia debe denegarse si ha sido anulada en el país en que se dictó. Los tribunales alemanes, por ejemplo, han adoptado la posición basada en la versión anterior del Código de Procedimiento Civil, según el cual la validez (“*Rechtswirksamkeit*”) de una sentencia arbitral extranjera era condición necesaria para su ejecución⁵⁴, así como

⁵¹ *PT Putrabali Adyamulia v. S.A. Rena Holding*, Tribunal de Casación, Francia, 05-18053, 29 de junio de 2007, 2007 REV. ARB. 507, que afirmó *PT Putrabali Adyamulia v. S.A. Rena Holding*, Tribunal de Apelaciones, París, Francia, 31 de marzo de 2005, 2006 REV. ARB. 665.

⁵² Cour d’appel de París, 18 de enero de 2007, *Société S.A. Lesbats et Fils v. Volker le Docteur Grub*.

⁵³ *Chromalloy Aeroservices Inc. v. Ministry of Defence of the Republic of Egypt*, 939 F. Supp. 907 (D.D.C.1996). Véase David W. Rivkin, *The Enforcement of Awards Nullified in the Country of Origin: The American Experience*, in ICCA CONGRESS SERIES NO. 9, IMPROVING THE EFFICIENCY OF ARBITRATION AGREEMENTS AND AWARDS: 40 YEARS OF APPLICATION OF THE NEW YORK CONVENTION 528 (A.J. van den Berg ed., 1998); véase Emmanuel Gaillard, *The Relationship of the New York Convention with other Treaties and with Domestic Law*, en ENFORCEMENT OF ARBITRATION AGREEMENTS AND INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS: THE NEW YORK CONVENTION IN PRACTICE (E. Gaillard, D. Di Pietro eds., 2008), págs. 80 a 86; Georgios C. Petrochilos, *Enforcing Awards Annulled In Their State Of Origin Under The New York Convention*, 48 ICLQ 856 (1999).

⁵⁴ Oberlandesgericht de Rostock, Alemania, 1 Sch 03/99, 28 de octubre de 1999. Véase Klaus Sachs, *The Enforcement of Awards Nullified in the Country of Origin: The German Experience*, en ICCA CONGRESS SERIES NO. 9, IMPROVING THE EFFICIENCY OF ARBITRATION

en el nuevo Código de Procedimiento Civil alemán, según el cual el reconocimiento y la ejecución “se otorgarán de conformidad con [la Convención de Nueva York]”, incluidos los motivos de denegación con arreglo al artículo V 1) e)⁵⁵.

48. De modo análogo, los tribunales de los Estados Unidos de América no han seguido la decisión *Chromalloy* de 1996 y se han rehusado a ejecutar sentencias que hayan sido anuladas o suspendidas⁵⁶. Así, por ejemplo, en la decisión *Baker Marine*, de 1999, el Tribunal de Apelaciones del segundo circuito denegó la ejecución de dos sentencias dictadas en Nigeria y anuladas por los tribunales nigerianos, rechazando el argumento de la parte interesada de que la sentencias habían sido anuladas por razones que no hubieran sido reconocidas con arreglo al derecho de los Estados Unidos como motivos válidos para dejar el laudo sin efecto. El Tribunal razonó que la “aplicación mecánica del derecho de arbitraje interno a las sentencias extranjeras con arreglo a la Convención socavaría gravemente la irrevocabilidad y sería fuente constante de fallos contradictorios”⁵⁷.

49. Por otro lado, la negativa de un tribunal a ejecutar un laudo que ha sido anulado o suspendido podría constituir una violación del Convenio Europeo que, en los casos en que resulte aplicable⁵⁸, limita expresamente los motivos de denegación que se establecen en el artículo V de la Convención de Nueva York. A este respecto, el artículo IX 2) del Convenio Europeo dispone que en el caso de que un Estado sea parte tanto en el Convenio Europeo como en la Convención de Nueva York, la facultad discrecional del tribunal de negarse a ejecutar el laudo aduciendo que había sido anulado estará limitada a los casos en que el laudo haya sido anulado por una de las razones limitadas que se enumeran en su artículo IX 1)⁵⁹.

AGREEMENTS AND AWARDS: 40 YEARS OF APPLICATION OF THE NEW YORK CONVENTION 552 (A.J. van den Berg ed., 1998).

⁵⁵ Bundesgerichtshof, Alemania, III ZB 14/07, 21 de mayo de 2007.

⁵⁶ *Baker Marine Ltd. v. Chevron Ltd.*, Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, segundo circuito, Estados Unidos de América, 12 de agosto de 1999, 191 F.3d 194 (segundo circuito, 1999); *TermoRio S.A. E.S.P. v. Electricadora del Atlántico S.A. E.S.P.*, Tribunal de Distrito, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, 17 de marzo de 2006, 421 F. Supp. 2d 87 (D.D.C. 2006); *Martin Spier v. Calzaturificio Tecnica, S.p.A.*, Tribunal de Distrito, Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de América, 22 de octubre de 1999, 86 Civ. 3447.

⁵⁷ *Baker Marine Ltd. v. Chevron Ltd.*, Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, segundo circuito, Estados Unidos de América, 12 de agosto de 1999, 191 F.3d 194 (segundo circuito, 1999). El Tribunal se apartó del caso *Chromalloy* basándose en la nacionalidad de la parte interesada, que no era ciudadana de los Estados Unidos, y de una disposición de la cláusula compromisoria según la cual la decisión del árbitro “no podía estar sujeta a apelación ni a ningún otro recurso”.

⁵⁸ Para la aplicación del Convenio Europeo, véase United Nations Treaty Collection, en http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsg_no=XXII-2&chapter=22&lang=en.

⁵⁹ El artículo IX 1), que aquí se cita en su totalidad, dispone lo siguiente: “1. La anulación en uno de los Estados contratantes de un laudo arbitral amparado por el presente Convenio constituirá causa de denegación en lo referente al reconocimiento o ejecución de dicho laudo en otro Estado contratante, solo en el caso de que tal anulación se hubiere llevado a efecto en aquel Estado en el cual o conforme a cuya ley fue pronunciado el fallo arbitral y ello por una de las siguientes razones: a) las partes en el acuerdo o compromiso arbitral estaban, con sujeción a la ley a ellas aplicable, afectadas de una incapacidad de obrar, o dicho acuerdo o compromiso no era válido con arreglo a la ley a la cual los sometieron las partes o, en caso de no haber indicación al respecto, conforme a la ley del país en donde se dictó el laudo; o b) la parte que pide la

50. En vista de su obligación en virtud del Convenio Europeo, el Tribunal Supremo austríaco ejecutó un laudo que había sido anulado por violar las normas de orden público de Eslovenia, razonando que “en virtud del artículo IX 1) del Convenio Europeo, incluso la anulación de un laudo por razones de orden público del país de origen (...) no es uno de los motivos de denegación enumerados (...) y no es razón, por tanto, para denegar la ejecución en el Estado ejecutante”⁶⁰.

d. Casos en que el derecho interno es más favorable que el artículo VI

51. El artículo VI de la Convención de Nueva York establece que un tribunal ante el cual se haya pedido la ejecución de una sentencia arbitral “podrá”, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia si esta ha sido objeto de una demanda de anulación en el país en que se otorgó, o con arreglo a cuya ley se otorgó. Guiándose por el artículo VII 1) de la Convención, los tribunales han aplicado las leyes nacionales más favorables al reconocimiento y la ejecución del artículo VI a fin de evitar todo efecto suspensivo de una demanda de anulación.

52. Por ejemplo, en una decisión de 1999, el Tribunal de Apelaciones de Luxemburgo consideró el argumento aducido por la parte que se oponía a la ejecución de que un laudo dictado en Suiza no tenía fuerza de cosa juzgada en vista de la demanda entablada para anular la sentencia arbitral ante el Tribunal Supremo Federal suizo y que, en virtud del artículo VI de la Convención de Nueva York, los procedimientos de ejecución iniciados en Luxemburgo debían suspenderse en espera de esa decisión. Rechazando este argumento, el Tribunal observó que “el principio de *favor arbitrandum* (...) se extiende a toda la Convención” y, en particular, al artículo VII 1), que tiene por objeto “hacer posible la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras en el mayor número posible de casos”. El Tribunal razonó que “de conformidad con la Convención, el Tribunal de Luxemburgo solo podía denegar la ejecución por uno de los motivos mencionados en su derecho nacional”. Puesto que el artículo 1028(3) del Código de Procedimiento Civil de Luxemburgo no incluye la impugnación del laudo en el extranjero entre los motivos de denegación, el Tribunal se rehusó a suspender su decisión y ejecutó el laudo⁶¹.

anulación del laudo no había sido informada debidamente sobre el nombramiento del árbitro o sobre el desarrollo del procedimiento arbitral, o le había sido imposible, por cualquier otra causa hacer valer sus alegaciones o recursos; o c) el laudo se refiere a una controversia no prevista en el compromiso arbitral o no incluida dentro de lo establecido en la cláusula compromisoria; o contiene decisiones sobre materias que sobrepasen los términos del compromiso arbitral de la cláusula compromisoria, entendiéndose, empero, que si las resoluciones del laudo que versen sobre cuestiones sometidas al arbitraje, puedan ser separadas o disociadas de aquellas otras resoluciones concernientes a materias no sometidas al arbitraje, las primeras podrán no ser anuladas, o d) la constitución o composición del tribunal de árbitros o el procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo o compromiso entre las partes o, no habiendo existido tal acuerdo o compromiso, a lo establecido en el artículo IV del presente Convenio. 2. En las relaciones entre aquellos Estados Contratantes que sean al mismo tiempo partes en el Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, el párrafo 1 del presente artículo viene a restringir la aplicación del artículo V, párrafo 1 e) de [la Convención] de Nueva York únicamente en los casos de anulación expuestos en dicho párrafo 1”.

⁶⁰ Tribunal Supremo, Austria, 26 de enero de 2005, 3Ob221/04b.

⁶¹ *Sovereign Participations International S.A. v. Chadmore Developments Ltd.*, Tribunal de Apelaciones, Luxemburgo, 28 de enero de 1999.

53. Los tribunales franceses también se han negado a suspender los procedimientos de ejecución mientras se resuelve una demanda de anulación de un laudo. En el caso *Bargues Agro* de 2004, por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones de París se rehusó a suspender la ejecución de un laudo dictado en Bélgica mientras estaba pendiente en ese país una demanda de anulación del laudo, aplicando de ese modo las disposiciones más favorables del derecho francés⁶². El Tribunal observó que, puesto que el laudo se había dictado en el contexto de un arbitraje internacional, no se fundaba en el ordenamiento jurídico nacional de Bélgica y su posible anulación no podía impedir su reconocimiento y ejecución en otro Estado Contratante. El Tribunal sostuvo, pues, que el artículo VI de la Convención “no era aplicable en el contexto del reconocimiento y la ejecución de una laudo con arreglo [al entonces aplicable] artículo 1502 del Código de Procedimiento Civil”.

e. Otras prácticas del derecho interno más favorables

54. Los tribunales alemanes se han basado en el artículo VII 1) de la Convención de Nueva York para aplicar el principio del derecho interno de la preclusión, según el cual toda parte que haya participado en un procedimiento de arbitraje sin impugnar un defecto conocido ante el tribunal de arbitraje no podrá, en general, invocar ese defecto como motivo para la denegación del reconocimiento o la ejecución del laudo⁶³. Los tribunales alemanes han interpretado el artículo 1044(2)(1) del antiguo Código de Procedimiento Civil en el sentido de que imponía la preclusión de las objeciones contra el laudo basadas, por ejemplo, en la falta de validez de un acuerdo de arbitraje, si ese motivo hubiera podido invocarse en una demanda de anulación del laudo en el país donde este se dictó y la parte interesada no hubiera aprovechado esa posibilidad.

55. El Código de Procedimiento Civil alemán no contiene disposiciones concretas que enumeren los motivos de denegación del reconocimiento o la ejecución de un laudo, sino que prevén en su lugar, que “el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras se otorgarán de conformidad con la Convención de Nueva York”⁶⁴. Existe una divergencia de opiniones entre los tribunales alemanes sobre la cuestión de si el principio de preclusión puede aplicarse sobre la base de la Convención de Nueva York exclusivamente. Algunos tribunales han sostenido que, si bien los motivos de denegación de la ejecución con arreglo al artículo V de la Convención de Nueva York no permiten, en ese sentido, la preclusión de las objeciones, un tribunal alemán podría, empero, aplicar el principio pese al hecho de que este no encuentre expresión explícita en el actual Código de Procedimiento Civil⁶⁵.

⁶² *Société Bargues Agro Industries S.A. v. Société Young Pecan Company*, Tribunal de Apelaciones, París, Francia, 10 de junio de 2004.

⁶³ Oberlandesgericht de Dusseldorf, Alemania, 8 de noviembre de 1971; Bundesgerichtshof, Alemania, III ZR 206/82, 10 de mayo de 1984. Véase también Albert Jan van den Berg, *The German Arbitration Act 1998 and the New York Convention 1958*, en *LAW OF INTERNATIONAL BUSINESS AND DISPUTE SETTLEMENT IN THE 21ST CENTURY - LIBER AMICORUM KARL-HEINZ BOCKSTIEGEL 783* (R.G. Briner, Y.L. Fortier, P.K. Berger, J. Bredow eds., 2001).

⁶⁴ Alemania, Código de Procedimiento Civil, artículo 1061.

⁶⁵ Por ejemplo, Oberlandesgericht, Karlsruhe, Alemania, 9 Sch 02/05, 27 de marzo de 2006; Oberlandesgericht de Karlsruhe, Alemania, 9 Sch 02/09, 4 de enero de 2012. Algunos tribunales

56. En la fecha de preparación de la presente guía, el Tribunal Federal alemán, en su decisión más reciente en la materia, afirmó que la preclusión de las objeciones debía tener una aplicabilidad limitada. Según el Tribunal, no supondría necesariamente mala fe que una parte señalase un defecto por primera vez en la etapa de la ejecución, de modo que dicha parte quedaría imposibilitada de hacerlo solo cuando las circunstancias indicaran que la conducta de esa parte parecía contrariar la buena fe y el principio de coherencia con la conducta anterior (“*venire contra factum proprium*”)⁶⁶.

ARTÍCULO VII 2)

57. La Convención de Nueva York fue concebida para reemplazar el Protocolo sobre cláusulas de arbitraje de Ginebra, de 1923, y la Convención internacional para la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras de Ginebra, de 1927 (conocidos los dos como “Tratados de Ginebra”), por considerarse que el marco jurídico que ofrecían era demasiado engorroso para la ejecución de sentencias arbitrales, en vista de la expansión del comercio internacional después de la segunda guerra mundial.

58. Fue solo el 10 de junio de 1958, durante una de las últimas sesiones de la Conferencia de Nueva York, cuando se agregaron a la Convención de Nueva York las disposiciones relativas a la validez de la ejecución del acuerdo de arbitraje (lo que es actualmente el artículo II)⁶⁷. Puesto que el Protocolo sobre cláusulas de arbitraje de Ginebra, de 1923 (el “Protocolo de Ginebra”), ya se ocupaba de estas cuestiones, el Protocolo de Ginebra quedó incorporado en las nuevas disposiciones que revocaban la Convención de Ginebra⁶⁸.

59. Según la documentación de la labor preparatoria, se sugirió que el artículo VII 2) dispusiera expresamente que los Tratados de Ginebra quedaban sin efecto (“dejarán de surtir efecto”) entre los Estados Contratantes “a partir del momento en que (...) [la Convención de Nueva York] tenga fuerza obligatoria para ellos”. La frase “y en la medida en que” se introdujo en el texto para tener en cuenta el caso de los Estados Contratantes que no quedarían obligados por la Convención de Nueva York en todos sus territorios simultáneamente y no para garantizar que se siguieran aplicando los Tratados de Ginebra⁶⁹. Los documentos de la labor preparatoria confirman además que la sustitución prescrita por el artículo VII 2) se refiere a los

inferiores han llegado a la conclusión de que, en vista de la falta de una disposición explícita al respecto, con arreglo a la Convención de Nueva York no puede invocarse la preclusión de objeciones. Véase, por ejemplo, Bayerisches Oberstes Landesgericht, Alemania, 4 Z Sch 50/99, 16 de marzo de 2000; Oberlandesgericht de Celle, Alemania, 8 Sch 11/02, 4 de septiembre de 2003.

⁶⁶ Bundesgerichtshof, Alemania, III ZB 100/09, 16 de diciembre de 2010.

⁶⁷ Labor preparatoria, Conferencia de las Naciones Unidas sobre arbitraje comercial internacional, acta resumida de la 24ª sesión, E/CONF.26/SR.24, pág. 4.

⁶⁸ Labor preparatoria, Conferencia de las Naciones Unidas sobre arbitraje comercial internacional, acta resumida de la 24ª sesión, E/CONF.26/SR.24.

⁶⁹ Labor preparatoria, Conferencia de las Naciones Unidas sobre arbitraje comercial internacional, texto de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras en su forma aprobada por el Comité de redacción de manera provisional el 6 de junio de 1958, E/CONF.26/L.61, págs. 3 y 4; Labor preparatoria, Conferencia de las Naciones Unidas sobre arbitraje comercial internacional, acta resumida de la 24ª sesión, E/CONF.26/SR.24, pág. 4. Véanse también las observaciones del Oberlandesgericht de Dusseldorf, 8 de noviembre de 1971.

Tratados de Ginebra en su integridad: una propuesta de limitar la sustitución en la medida en que fueran incompatibles con la Convención de Nueva York fue rechazada durante el proceso de redacción⁷⁰.

60. Las normas de reconocimiento y ejecución en virtud de la Convención de Nueva York representaban una mejora considerable de varios aspectos del régimen previsto en los Tratados de Ginebra.

61. En primer lugar, la Convención de Ginebra, que se aplicaba a los laudos basados en los acuerdos concertados con arreglo al Protocolo de Ginebra, preveía la ejecución de un laudo extranjero solo en caso de que la parte que procuraba invocarlo pudiera demostrar que el laudo era “definitivo” en su país de origen⁷¹. Por consiguiente, una parte interesada tenía que obtener un *exequatur* en el país en que se había dictado el laudo antes de obtener la ejecución en otro país, lo cual daba lugar a un requisito de “*exequatur* doble”. El régimen de la Convención de Nueva York, más liberal, no exige que el laudo sea definitivo, sino tan solo que sea “vinculante”.

62. En segundo lugar, para que el Protocolo de Ginebra y la Convención de Ginebra fueran aplicables, ambas partes en el arbitraje tenían que estar sujetas a la jurisdicción de los Estados partes en los respectivos tratados. La Convención de Nueva York, en cambio, solo exige que la sentencia arbitral haya sido dictada en el territorio de otro Estado Contratante o en el Estado ejecutante si se considera que la sentencia arbitral no es nacional en el Estado donde se procura obtener el reconocimiento y la ejecución.

63. En tercer lugar, la carga de la prueba en virtud de la Convención de Nueva York es menos onerosa para la parte que trata de obtener la ejecución. Con arreglo al artículo I de la Convención de Ginebra, una parte interesada tenía que demostrar la existencia de un acuerdo de arbitraje válido, relativo a una cuestión de arbitraje; que los procedimientos de arbitraje se habían llevado a cabo con el acuerdo de las partes, y también que la sentencia se había hecho firme y definitiva en el lugar del arbitraje y no era contraria al orden público del Estado que otorgaba el reconocimiento. En virtud de la Convención de Nueva York, la parte interesada en la ejecución solo tiene que presentar al tribunal el laudo original (o copia debidamente autenticada), junto con el acuerdo de arbitraje original (o copia debidamente autenticada). En virtud de la Convención de Nueva York, incumbe a la parte que se oponga a la ejecución demostrar la existencia de uno de los motivos de denegación enumerados en el artículo V de la Convención de Nueva York.

64. La jurisprudencia existente sobre el artículo VII 2) confirma el principio de que los Tratados de Ginebra dejarán de aplicarse al reconocimiento y la ejecución

⁷⁰ Labor preparatoria, Conferencia de las Naciones Unidas sobre arbitraje comercial internacional, acta resumida de la 18ª sesión, E/CONF.26/SR.18, pág. 7.

⁷¹ Este concepto estaba definido en el artículo 1 d) de la Convención de Ginebra de 1927 como un laudo que i) no estaba sujeto a ninguna forma de recurso ni ii) estaba sujeto a procedimientos pendientes que impugnaban su validez.

de sentencias arbitrales extranjeras en los Estados Contratantes para los cuales la Convención de Nueva York tenga fuerza obligatoria⁷².

65. Salvo contadas excepciones, todos los Estados que se habían adherido a los Tratados de Ginebra han pasado ahora a ser partes en la Convención de Nueva York⁷³. Por consiguiente, en la actualidad el artículo VII 2) es de pertinencia limitada en la práctica.

⁷² Por ejemplo, *S.p.A. Nosegno e Morando v. Bohne Friedrich und Co-Import-Export*, Corte Di Cassazione, Italia, 20 de enero de 1977; *Jassica S.A. v. Ditta Polojaz*, Corte di Appello, Trieste, Italia, 2 de julio de 1982; Tribunal Supremo, Austria, 21 de febrero de 1978; Oberlandesgericht de Dusseldorf, 8 de noviembre de 1971; *Trefileries & Ateliers de Commerc (T.A.C.) v. Société Philipp Brothers France et Société Derby & Co. Limited*, Tribunal de Apelación, Nancy, Francia, 5 de diciembre de 1980; *Minister of Public Works of the Government of the State of Kuwait v. Sir Frederick Snow & Partners*, Cámara de los Lores, Inglaterra, 1 de marzo de 1984, [1984] A.C. 426.

⁷³ No está clara la situación jurídica de las ex colonias que eran Estados Contratantes de los Tratados de Ginebra, puesto que algunas de ellas no han hecho anuncios oficiales en cuanto a su situación. Véase Dirk Otto, *Article IV*, en RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF ARBITRAL AWARDS: A GLOBAL COMMENTARY ON THE NEW YORK CONVENTION 143 (H. Kronke, P. Nascimento et al. eds, 2010).

II. COMERCIO ELECTRÓNICO

A. Informe del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico sobre la labor realizada en su 46º período de sesiones (Viena, 29 de octubre a 2 de noviembre de 2012)

(A/CN.9/761)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-5
II. Organización del período de sesiones	6-12
III. Deliberaciones y decisiones	13
IV. Cuestiones jurídicas relativas a la utilización de documentos transmisibles electrónicos	14-93
A. Alcance de la labor	18-23
B. Cuestiones jurídicas relativas a los documentos transmisibles electrónicos	24-82
C. Otras cuestiones relativas a los documentos transmisibles electrónicos	83-89
D. Labor futura	90-93
V. Asistencia técnica y coordinación	94-100
VI. Otros asuntos	101

I. Introducción

1. En su 42º período de sesiones, celebrado en 2009, la Comisión pidió a la Secretaría que preparara un estudio sobre los documentos transmisibles electrónicos teniendo en cuenta las propuestas recibidas durante ese período de sesiones (A/CN.9/681 y Add.1 y A/CN.9/682)¹.

2. En su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión dispuso de más información sobre el empleo de las comunicaciones electrónicas para la transmisión de derechos sobre bienes, en particular, con respecto al empleo de la inscripción registral para la creación y transmisión de derechos (A/CN.9/692, párrs. 12 a 47). En ese período de sesiones la Comisión pidió a la Secretaría que organizara un coloquio sobre los temas correspondientes, a saber, los documentos transmisibles electrónicos, la gestión de datos de identificación personal, el comercio electrónico por conducto de dispositivos móviles y los sistemas electrónicos de ventanilla única².

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párr. 343.*

² *Ibid., sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), párr. 250.*

3. En su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión tuvo ante sí una nota de la Secretaría (A/CN.9/728 y Add.1) en la que se resumían las deliberaciones del coloquio sobre el comercio electrónico (Nueva York, 14 a 16 de febrero de 2011)³. Tras las deliberaciones sostenidas al respecto, la Comisión encomendó al Grupo de Trabajo que emprendiera trabajos en el ámbito de los documentos transmisibles electrónicos⁴. Se señaló que esos trabajos resultarían útiles no solo para promover las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional en general, sino también para ocuparse de ciertos aspectos concretos, como el de contribuir a la aplicación de las Reglas de Rotterdam⁵. Además, la Comisión convino en que la labor relativa a los documentos transmisibles electrónicos podía abarcar aspectos de otros asuntos, como la gestión de los datos de identificación personal, el comercio electrónico por conducto de dispositivos móviles y los sistemas electrónicos de ventanilla única⁶.

4. En su 45º período de sesiones (Viena, 10 a 14 de octubre de 2011), el Grupo de Trabajo inició su labor sobre diversas cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos transmisibles electrónicos, entre ellas una posible metodología para su labor futura (A/CN.9/737, párrs. 14 a 88). También examinó la labor realizada sobre ese tema por otras organizaciones internacionales (A/CN.9/737, párrs. 89 a 91).

5. En su 45º período de sesiones, celebrado en 2012, la Comisión expresó su reconocimiento al Grupo de Trabajo por los progresos realizados y encomió la labor de la Secretaría⁷. En general se apoyó la propuesta de que el Grupo de Trabajo prosiguiera su labor en relación con los documentos transmisibles electrónicos y se subrayó la necesidad de contar con un régimen internacional que facilitara su utilización a través de las fronteras⁸. En ese contexto, se señaló la conveniencia de determinar clases concretas de documentos transmisibles electrónicos o cuestiones especiales conexas y de concentrarse en ellas⁹. Tras deliberar al respecto, la Comisión reafirmó el mandato del Grupo de Trabajo en relación con los documentos transmisibles electrónicos y pidió a la Secretaría que siguiera informando sobre novedades pertinentes relacionadas con el comercio electrónico¹⁰.

II. Organización del período de sesiones

6. El Grupo de Trabajo, integrado por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 46º período de sesiones en Viena del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2012. Asistieron representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Argelia, Austria, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Honduras, Israel, Italia, Japón, Kenya,

³ La información relativa a este coloquio disponible en la fecha del presente informe se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/electronic-commerce-2010.html.

⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17)*, párr. 238.

⁵ *Ibid.*, párr. 235.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, *Sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17)*, párr. 82.

⁸ *Ibid.*, párr. 83.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, párr. 90.

Malasia, Malta, México, Nigeria, Pakistán, República Checa, República de Corea, Singapur, Tailandia, Turquía, Ucrania y Venezuela (República Bolivariana de).

7. Asistieron también al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Belarús, Bélgica, Chipre, Ecuador, Hungría, Indonesia, Iraq, Polonia, Qatar, República de Moldova, República Dominicana y Viet Nam.

8. Asistieron, además, observadores de la Unión Europea.

9. Asimismo estuvieron presentes observadores de las siguientes organizaciones internacionales:

a) *Organizaciones intergubernamentales*: Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) y Organización Mundial de Aduanas (OMA);

b) *Organizaciones internacionales no gubernamentales*: Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Consejo de la Asamblea Interparlamentaria de Naciones Miembros de la Comunidad de Estados Independientes, *European Multi-Channel and Online Trade Association*, Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Asimilados, Foro de Conciliación y Arbitraje Internacionales, Instituto de Derecho y Tecnología (Universidad de Masaryk), Instituto Europeo de Derecho y *New York State Bar Association*.

10. El Grupo de Trabajo eligió a los siguientes miembros de la Mesa:

Presidente: Sr. Agustín MADRID PARRA (España)

Relatora: Sra. Kachida MEETORTHARN (Tailandia)

11. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí los siguientes documentos: a) programa provisional anotado (A/CN.9/WG.IV/WP.117); b) una nota de la Secretaría sobre cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos transmisibles electrónicos (A/CN.9/WG.IV/WP.118 y Add.1); c) cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos transmisibles electrónicos: propuesta de los Gobiernos de Colombia, España y los Estados Unidos (A/CN.9/WG.IV/WP.119), y d) un documento presentado por el equipo de trabajo de la *American Bar Association* sobre gestión de la identidad digital (A/CN.9/WG.IV/WP.120).

12. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:

1. Apertura del período de sesiones.
2. Elección de la Mesa.
3. Aprobación del programa.
4. Examen de las cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos transmisibles electrónicos.
5. Asistencia técnica y coordinación.
6. Otros asuntos.
7. Aprobación del informe.

III. Deliberaciones y decisiones

13. El Grupo de Trabajo inició sus deliberaciones sobre las cuestiones jurídicas relativas a la utilización de documentos transmisibles electrónicos basándose en los documentos A/CN.9/WG.IV/WP.118 y Add.1. Las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo sobre esos temas se recogen en el capítulo IV *infra*.

IV. Cuestiones jurídicas relativas a la utilización de documentos transmisibles electrónicos

14. Al inicio del debate se informó al Grupo de Trabajo de los resultados de las consultas que se habían efectuado en los Estados con respecto a los documentos transmisibles electrónicos. Si bien en un par de Estados las consultas mostraban que el uso de ese tipo de documentos despertaba poco o ningún interés en los distintos sectores o que la necesidad de utilizarlos en el sector financiero era limitada o inexistente, se señaló que en las consultas realizadas en un número considerable de otros Estados se habían recibido respuestas favorables de varios sectores.

15. Se sugirió que la labor relativa a los documentos transmisibles electrónicos debía basarse estrictamente en las necesidades comerciales reales y servir para resolver los problemas que pudieran detectarse. En respuesta, se señaló que se habían determinado necesidades comerciales reales. Se destacó además que posibilitar el empleo de documentos transmisibles electrónicos traería beneficios evidentes a los sectores en cuestión.

16. A ese respecto se señaló que al facilitarse el empleo de documentos transmisibles electrónicos podrían disminuir los costos de las operaciones comerciales, a la vez que aumentaban su eficiencia y seguridad. Se hizo referencia a las ventajas que podría conllevar el empleo de pagarés electrónicos y resguardos de almacén electrónicos en los sistemas nacionales. Se destacó la dimensión transfronteriza que prevalecía en el empleo de conocimientos de embarque electrónicos, que exigían leyes armonizadas que permitieran su uso, para cuya elaboración la CNUDMI se encontraba en una posición única, y que también podía implicar el uso de letras de cambio electrónicas como documentos comerciales. Por último, se señaló que unas reglas detalladas podrían servir de complemento útil de las disposiciones del Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo (las “Reglas de Rotterdam”) en relación con los documentos de transporte negociables electrónicos.

17. El Grupo de Trabajo convino en que la gran cantidad de información reunida durante las consultas confirmaba la conveniencia de proseguir la labor relacionada con los documentos transmisibles electrónicos y la posible utilidad de la orientación sobre esa cuestión.

A. Alcance de la labor

1. Documentos transmisibles electrónicos

18. En cuanto al alcance de la labor, si bien se sugirió que sería conveniente que el Grupo de Trabajo se centrara en determinados tipos de documentos transmisibles electrónicos o en cuestiones específicas relacionadas con esos documentos, en general se opinó que el Grupo de Trabajo debería formular reglas generales basadas en un enfoque funcional y que tales reglas generales debían ser lo suficientemente amplias para abarcar diversos tipos de documentos transmisibles electrónicos, incluidos los que se utilizaban en operaciones mercantiles y monetarias. Se hicieron notar varios logros importantes que se habían conseguido en la formulación de reglas generales basadas en un enfoque funcional y, en consecuencia, se sugirió que se adoptara un enfoque similar con respecto a los documentos transmisibles electrónicos. Además se propuso que, si fuera necesario, podían formularse reglas específicas sobre determinados tipos de documentos transmisibles electrónicos después de haber preparado las reglas generales.

19. Se indicó que la descripción general de los documentos y títulos transmisibles que quedaban excluidos del ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (la “Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas”) en virtud del artículo 2, párrafo 2, de la Convención podría servir de punto de partida para el examen, dado que se trataba de una descripción general pero exhaustiva de los documentos transmisibles electrónicos.

20. Se reiteró que el Grupo de Trabajo no debía ocuparse de los asuntos que se rigieran por el derecho sustantivo. Además se destacó que la terminología debía elegirse con cuidado para dar cabida al derecho sustantivo de todas las tradiciones jurídicas.

21. A continuación el Grupo de Trabajo examinó la distinción entre la transferibilidad y la negociabilidad. Se convino en que la negociabilidad se refería a los derechos básicos del tenedor del título en virtud del derecho sustantivo y, por lo tanto, el debate debía centrarse en la transferibilidad.

22. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo adoptó la hipótesis de trabajo de que por documentos transmisibles electrónicos debía entenderse “el equivalente electrónico de todo documento o título transferible que faculte a su portador o beneficiario para reclamar la entrega de las mercancías o el pago de una suma de dinero” (véase el artículo 2 del párrafo 2 de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas). Se procedió a aclarar que los documentos transmisibles electrónicos no debían incluir los equivalentes electrónicos de valores bursátiles, como acciones y obligaciones, ni los medios electrónicos de pago.

2. Gestión de los documentos transmisibles electrónicos

23. Con respecto a la existencia de distintos modelos de gestión de los documentos transmisibles electrónicos (basados en un registro, en pruebas de apoyo (*tokens*) o en otros sistemas), se explicó que debía respetarse la neutralidad no solo en cuanto a la tecnología sino también en cuanto al sistema elegido.

B. Cuestiones jurídicas relativas a los documentos transmisibles electrónicos

1. Creación y emisión de documentos transmisibles electrónicos

24. Se resaltó la importancia de definir un equivalente funcional del concepto de posesión de documentos en papel a fin de identificar la parte con derecho a exigir el cumplimiento del documento transmisible electrónico. Se sugirió que podría lograrse la equivalencia funcional mediante el concepto de control del documento transmisible electrónico. Se señaló que la atribución del control era inherente a la creación de documentos transmisibles electrónicos. Se hizo hincapié en que el concepto de control debía formularse de manera que resultara neutro desde el punto de vista de la tecnología.

25. Se sugirió también que, para establecer el control de un documento transmisible electrónico, los siguientes requisitos se podían aplicar a la tecnología: autenticidad del documento y de sus firmas; originalidad e integridad del documento, al menos durante el periodo de tiempo que exigiera la ley; y capacidad de identificar al tenedor, teniendo en cuenta que en determinadas circunstancias podía ser conveniente no revelar su identidad. Se señaló que el capítulo 10 de las Reglas de Rotterdam podía servir de orientación para el examen del concepto de control.

26. Se explicó que la práctica comercial demostraba el uso habitual de documentos en papel emitidos al portador. Se añadió que las reglas sobre los documentos transmisibles electrónicos debían hacer posible ese tipo de uso y permitir el anonimato en la medida en que lo permitiera la tecnología, por ejemplo, mediante el uso de seudónimos. A ese respecto, también se afirmó que las partes tal vez podrían no ser identificadas en el sistema de gestión de documentos transmisibles electrónicos pero sí permanecer identificables conforme a las características de ese sistema o la tecnología utilizada. No obstante, se señaló también que las disposiciones reglamentarias exigían cada vez con más frecuencia que se identificara a las partes implicadas, particularmente en las operaciones financieras.

27. Se indicó que podría ser provechoso para el Grupo de Trabajo considerar si sería apropiado distinguir entre un tercero prestador de servicios con licencia de otro sin licencia, la cuestión de la responsabilidad del tercero prestador de servicios, así como la cuestión de cualquier posible responsabilidad del emisor del documento respecto a la elección del tercero prestador de servicios. Se señaló que los artículos 9 y 10 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas, relativos al proceder y la fiabilidad del prestador de servicios de certificación, podían servir de orientación a ese respecto.

28. En lo que respecta a la creación de documentos transmisibles electrónicos, el Grupo de Trabajo reflexionó sobre si su ámbito de trabajo debía limitarse a la transposición de documentos transmisibles emitidos en papel al entorno electrónico o si debía abarcar también instrumentos nuevos que pudieran existir únicamente en el entorno electrónico. Se señaló que el examen de instrumentos nuevos entrañaría una labor relacionada con el derecho sustantivo, lo que no recaía dentro del mandato del Grupo de Trabajo. En ese contexto, se sugirió que el Grupo de Trabajo se centrara en los requisitos formales para la creación de documentos transmisibles

electrónicos, algunos de los cuales (por ejemplo, los de escritura y firma) ya se habían examinado en anteriores textos de la CNUDMI.

29. Tras las deliberaciones hubo acuerdo general en que el Grupo de Trabajo se centrara en posibilitar el empleo de documentos transmisibles electrónicos como equivalentes de los documentos transmisibles emitidos en papel. No obstante, se sugirió que aunque el Grupo de Trabajo no debía dedicarse a preparar reglas sustantivas para instrumentos que solo existirían en el entorno electrónico, esos instrumentos no debían excluirse del ámbito general de su labor sobre los documentos transmisibles electrónicos.

30. En cuanto a la creación de documentos transmisibles electrónicos, se resaltó la importancia de fomentar la confianza de los usuarios mediante un sistema seguro, eficaz y fiable.

31. El Grupo de Trabajo convino en que los términos “emisión” y “activación” estaban estrechamente relacionados pero eran diferentes. Se explicó que mientras que “emisión” podía tener connotaciones en el derecho sustantivo, “activación” se refería al paso físico o técnico de colocar el documento transmisible electrónico bajo el control de su primer tenedor. Se hizo referencia al artículo 8 b) de las Reglas de Rotterdam donde el término “emisión” se utilizó en relación con un documento electrónico de transporte. Se señaló además que debía examinarse el papel de toda tercera parte en la activación del documento, por ejemplo en calidad de agente del emisor. Se explicó que podía elaborarse un sistema basado en el registro para permitir que el emisor activara directamente el documento transmisible electrónico. Se mencionó la necesidad de distinguir entre las funciones de un registro y las de un archivo.

32. En cuanto a la información que había de exigirse para crear documentos transmisibles electrónicos, se acordó que debía ser la misma que para la creación del documento en papel equivalente. No obstante, se señaló que al tratarse de un documento de formato electrónico podría exigirse información técnica adicional, como un número de identificación asignado a ese documento. En ese contexto se mencionó que también debía tenerse en cuenta la necesidad de que hubiera consentimiento explícito o implícito para el empleo de documentos transmisibles electrónicos (conforme a lo dispuesto en el artículo 8, párrafo 2, de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas). Además se señaló que el formato electrónico permitía incluir en el documento más información de la que podía figurar en el equivalente impreso y que no se debía impedir a las partes añadir esa información si así lo hubieran acordado. Se señaló asimismo que el artículo 5 *bis* de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico también podía ser pertinente dado que permitía incorporar por remisión información obligatoria o adicional en el documento transmisible electrónico.

33. Se explicó que la singularidad no debía constituir un fin en sí, sino una forma de evitar múltiples reclamaciones basadas en múltiples documentos cuyo cumplimiento tuvieran derecho a exigir sus tenedores. Teniendo eso en cuenta, se señaló que los requisitos para lograr la singularidad podrían cambiar a la luz de la tecnología utilizada y de otras circunstancias. Se hizo referencia al artículo 9, párrafo 1, de las Reglas de Rotterdam como ejemplo de cómo lograr la singularidad estableciendo procedimientos para el empleo de los documentos electrónicos de transporte negociables.

34. No obstante, se expresó la opinión de que el objetivo principal de la singularidad era comprobar el contenido de la obligación que figurase en el documento transmisible electrónico y que el problema de las múltiples reclamaciones podría evitarse mediante el concepto de control que permitía identificar al tenedor legítimo.

35. Se expresó la opinión de que los sistemas basados en el registro podían elaborarse de manera que ofrecieran más fiabilidad respecto a la singularidad del documento transmisible electrónico, mientras que los sistemas basados en elementos de apoyo (*tokens*) tal vez no pudieran ofrecer el mismo nivel de fiabilidad si se dependía únicamente de sus características técnicas. En respuesta, se señaló que se disponía de sistemas basados en elementos de apoyo (*tokens*) y otros factores, como el número de entidades que tuvieran acceso al documento transmisible electrónico, podían influir en el nivel de fiabilidad de la singularidad del documento transmisible electrónico.

36. Se hizo referencia a las prácticas vigentes que preveían el empleo de múltiples originales en entornos donde se empleaban documentos en papel. Se citó el caso de los conocimientos de embarque en papel, emitidos en tres ejemplares originales. Se preguntó si sería técnicamente viable emular esa práctica en el entorno electrónico o si sería deseable teniendo en cuenta la mayor rapidez de transmisión y la mayor seguridad que ofrecían los medios electrónicos. Se hizo referencia al artículo 36, párrafo 2 d), de las Reglas de Rotterdam, que permitía la emisión de múltiples originales de los documentos de transporte negociables, pero no de los documentos electrónicos negociables transmisibles. Se señaló que durante las negociaciones de las Reglas de Rotterdam se había observado que las necesidades que en un entorno de documentos en papel se atendían mediante la emisión de varios originales podían ser satisfechas en el entorno electrónico mediante la emisión de un solo original.

37. El Grupo de Trabajo convino en que todo examen futuro de la cuestión de la singularidad habría de tener debidamente en cuenta los textos pertinentes de la CNUDMI. También convino en que la singularidad debía tener por objetivo dar derecho a un único tenedor del documento transmisible electrónico a exigir el cumplimiento del documento.

38. El Grupo de Trabajo prosiguió su debate basándose en la hipótesis de que el concepto de “control” sobre los documentos transmisibles electrónicos conseguiría la equivalencia funcional del concepto de “posesión” de documentos en papel. Se explicó que la idea de control era necesaria para designar al tenedor del documento de una forma fiable.

39. Se añadió que el tipo de procedimiento que debiera utilizarse para lograr el control era una cuestión secundaria. Se mencionaron distintos ejemplos de disposiciones legislativas relativas al control. Se señaló que, si bien algunas disposiciones se referían únicamente a la existencia de procedimientos adecuados, otras establecían con más detalle los requisitos de esos procedimientos. Se mencionó también que en los sistemas basados en el registro el tenedor del documento transmisible electrónico podía no tener el control real.

40. Se preguntó si era deseable asociar una presunción de fiabilidad a procedimientos que cumplieran determinados requisitos, que habían de describirse de una forma neutra desde el punto de vista de la tecnología. En respuesta, se

destacó que era necesario adoptar un enfoque prudente para evitar favorecer a un sistema o una tecnología determinados.

41. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo acordó que las reglas sobre el control debían tener como objetivo establecer la equivalencia funcional de la idea de posesión que se aplicaba a los documentos en papel mediante la identificación efectiva del tenedor que tuviera derecho a exigir el cumplimiento. Se acordó además que no hubiera ninguna referencia específica al tipo de sistema o de tecnología que habría de adoptarse para generar esa fiabilidad.

42. Se señaló que toda obligación de revelar la identidad del emisor o del primer tenedor figuraría en el derecho sustantivo aplicable. Por tanto, debía permitirse el anonimato a fin de trasladar al entorno electrónico las prácticas empresariales vigentes en relación con los documentos en papel. A nivel general, se sugirió que sería pertinente contar con disposiciones sobre la firma electrónica, incluso disposiciones preparadas por la CNUDMI, para establecer el vínculo entre los documentos transmisibles electrónicos y las partes interesadas.

43. Se señaló también que identificar al tenedor como la entidad con derecho a exigir el cumplimiento era diferente de revelar la identidad de esa entidad. Se dio el ejemplo del uso de un número de identificación personal (PIN) para la expedición de mercancías, práctica con la que se identificaba de forma fiable a la parte que tenía derecho a exigir el cumplimiento sin necesidad de revelar su identidad.

44. Se señaló que si se exigía la identificación previa de la parte para que esta accediera al sistema de gestión de documentos transmisibles electrónicos podría revelarse su identidad sobre la base de esa identificación previa. En cambio, en un sistema que no exigiera dicha identificación previa podrían hacer falta medidas adicionales para cumplir con el requisito de revelar la identidad.

2. Circulación de los documentos transmisibles electrónicos

45. Habida cuenta de las prácticas mercantiles vigentes, se propuso que se preparasen normas para permitir la modificación de los documentos transmisibles electrónicos. Se subrayó la necesidad de que las modificaciones se señalaran claramente como tales. Además se indicó que el traspaso del control de un documento transmisible electrónico, cuestión que se examina más abajo, se realizaría por lo general mediante la modificación del documento.

46. Se indicó que el tenedor que ejerciera el control del documento transmisible electrónico sería por lo general la parte que tendría derecho a efectuar esas modificaciones. No obstante, se instó a obrar con prudencia teniendo presente que cualquier regla sobre el particular no debería permitir al tenedor hacer modificaciones que afectasen la obligación básica del emisor sin su consentimiento. Por tanto, se sugirió que en lugar de ello se hiciera referencia a la parte autorizada para efectuar modificaciones, conforme a lo que determinara el derecho sustantivo.

47. Se indicó la necesidad de incluir el requisito de informar a las partes afectadas por la modificación cuando se fuera a efectuar tal modificación. Sin embargo, se afirmó que el requisito de notificar no existía necesariamente en el caso de los documentos en papel y que sería más apropiado mantener los mismos requisitos de notificación para los documentos transmisibles electrónicos que los establecidos para los documentos transmisibles emitidos en papel. Se expresaron observaciones

similares respecto a la cuestión del momento en que podrían introducirse modificaciones en los documentos transmisibles electrónicos.

48. En cuanto al modo de dar efecto a las modificaciones, se señaló que se trataba de una cuestión técnica que dependía en gran medida del sistema vigente. En las normas sobre modificaciones se debería reconocer que un documento transmisible electrónico podía modificarse y permitir que el sistema determinara la forma de efectuar las modificaciones.

49. Tras deliberar, se convino en que la norma que se habría de preparar debía reconocer la necesidad de ocuparse de las modificaciones y su efectividad, mientras que la cuestión de establecer qué parte podría efectuar las modificaciones y en qué circunstancias debía dejarse al derecho sustantivo. En ese contexto, se sugirió que sería útil contar con una definición del término “modificación”.

50. A continuación, el Grupo de Trabajo inició un debate sobre el traspaso del control. Se explicó que el traspaso del control sobre un documento transmisible electrónico debía tener el mismo efecto que la entrega y, si procedía, el endoso de un documento transferible en papel.

51. Se sugirió que los elementos que figuraban en el artículo 9, párrafo 1, de las Reglas de Rotterdam podían servir de punto de partida para la redacción de normas sobre el traspaso del control. No obstante, también se afirmó que las disposiciones del capítulo 3 de las Reglas de Rotterdam, incluido el artículo 9, debían tener un mayor grado de especificación para poder ofrecer el nivel deseable de orientación y que, para ese fin, era necesario contar con normas que establecieran procedimientos para lograr la equivalencia funcional de la transmisión de documentos en papel.

52. Se mencionaron otros posibles modelos legislativos, como el Artículo 7-106 del Código de Comercio Uniforme de los Estados Unidos de América. Concretamente, se sugirió que el criterio general utilizado en la subsección a) de esa disposición podría servir de orientación general.

53. En cuanto a la cuestión de los terceros prestadores de servicios, tales como los administradores de registros, se señaló que sus obligaciones podían surgir de los requisitos de los procedimientos que existieran para establecer y traspasar el control, así como de las características del sistema de gestión de los documentos transmisibles electrónicos, entre ellas, su fiabilidad y seguridad. Por tanto, se señaló que las normas no debían establecer funciones ni obligaciones adicionales para esos administradores de registros.

54. Se sugirió que podría ser útil para las futuras deliberaciones proporcionar una definición del concepto de control de un documento transmisible electrónico. En concreto, se señaló que si bien por lo general el tenedor tendría derecho a traspasar el control del documento transmisible electrónico, un examen más detallado de ese derecho exigía que hubiera consenso previo sobre la definición de control.

55. Se preguntó si las normas sobre el traspaso del control deberían permitir cambios en la manera de transmisión al portador, si el documento se había emitido al portador y viceversa. Se respondió que todas las opciones disponibles en el caso de los documentos transmisibles emitidos en papel deberían también aplicarse a los documentos transmisibles electrónicos.

56. Se planteó la cuestión del momento en que había de procederse al traspaso del control. A ese respecto, se mencionó la posibilidad de utilizar una norma similar a la que figuraba en el artículo 10 de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas para determinar el momento de envío y recepción de las comunicaciones electrónicas y, por tanto, el momento de la transmisión del documento transmisible electrónico.

57. Se observó que el establecimiento de una terminología coherente, posiblemente mediante definiciones, sería útil para determinar los casos relativos a la identificación de la capacidad jurídica de la parte (por ejemplo, el tenedor) frente a los relativos a la revelación de su identidad.

58. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en que se debían preparar, para examinarlas posteriormente, una definición del concepto de control y normas sobre el traspaso del control, teniendo en cuenta los modelos legislativos existentes y la necesidad de neutralidad desde el punto de vista de la tecnología. Concretamente, se señaló que debía evitarse imponer límites al número de traspasos si dichos límites no se aplicaban a los documentos en papel.

59. Se señaló que en las normas sobre la introducción de correcciones en los documentos transmisibles electrónicos influían excesivamente las aplicables a los documentos en papel y que sería deseable contar con nuevas normas que se refirieran específicamente a los errores que podían darse al introducir datos en el entorno electrónico. Esas normas podrían contemplar la introducción de correcciones antes y después de la emisión del documento. En el segundo caso, podría ser necesario el consentimiento de todas las partes interesadas. Con respecto a los sistemas basados en un registro, se resaltó la distinción entre los errores de las partes y los de los administradores de los registros.

60. Se señaló que las consecuencias de permitir correcciones de los documentos transmisibles electrónicos podían ser particularmente importantes, dado que esos documentos se empleaban en el comercio internacional entre partes lejanas y que las instituciones financieras exigían que se cumplieran parámetros estrictos en el momento de su presentación. Se destacó la necesidad de proteger a todas las partes involucradas, incluso mediante el requisito de contar con su consentimiento antes de poder efectuar una corrección.

61. Se examinó la posibilidad de introducir una norma parecida a la que figuraba en el artículo 14 de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas. Se afirmó que ese artículo tenía un alcance limitado pero aún así podría resultar útil para regular las cuestiones específicamente relacionadas con el empleo de medios electrónicos. En particular, se explicó que ese artículo se aplicaría únicamente a los casos en que se hubiera cometido un error al introducir los datos durante la interacción entre una persona física y un sistema automatizado de mensajes y cuando ese sistema de mensajes no ofreciera la oportunidad de corregir el error. Además debían cumplirse otros requisitos, por ejemplo, que la persona física no se hubiera beneficiado de la operación en cuestión. Se señaló que, en la práctica, era poco probable que se pudiera aplicar esa norma si el sistema de gestión de los documentos transmisibles electrónicos establecía el mismo procedimiento, ya fuere automatizado o manual, para todos los participantes.

62. Se añadió que los sistemas de gestión de los documentos transmisibles electrónicos permitirían normalmente el tratamiento de los errores cometidos al introducir los datos y que la competencia entre los distintos proveedores de esos

sistemas daría a las empresas la oportunidad de elegir un sistema que ofreciera esa opción. Dado que convenía evitar interferir en el derecho sustantivo, se acordó que debía adoptarse un enfoque prudente al considerar normas específicas sobre la introducción de correcciones en los documentos transmisibles electrónicos.

63. Se señaló que los ejemplos existentes de garantías y pignoraciones en relación con los documentos transmisibles electrónicos se solían encontrar en los sistemas basados en un registro que se utilizaban en el sector financiero. Se añadió que la necesidad de garantías y pignoraciones también surgía en relación con otros documentos transmisibles. Por ejemplo, se explicó que era frecuente que se ofrecieran conocimientos de embarque como garantía a instituciones financieras. En ese caso podría idearse un mecanismo que permitiera que la garantía primara sobre el tenedor que tuviera el control del documento.

64. Se hizo referencia a la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas, que proporcionaba orientación sobre el derecho sustantivo en materia de operaciones garantizadas con documentos e instrumentos negociables.

65. El Grupo de Trabajo acordó que se debían preparar normas sobre las garantías y pignoraciones en relación con los documentos transmisibles electrónicos, que esas normas debían poder aplicarse a todos los tipos de documentos y que debían ser neutras desde el punto de vista de la tecnología y los sistemas.

66. Se señaló que la división y la combinación de documentos transmisibles eran prácticas mercantiles comunes y que podría ser particularmente útil contar con una norma general que facilitara esa posibilidad para los equivalentes electrónicos.

67. En cuanto a la práctica vigente de dividir y combinar conocimientos de embarque, se explicó que, en algunos casos, los conocimientos de embarque existentes dejaban de tener efecto jurídico y se emitían nuevos conocimientos. Se añadió que, si bien era necesario que participaran el porteador y el cargador, existían distintas prácticas en cuanto al requisito del consentimiento de otras partes.

68. Se sugirió que los requisitos y efectos relativos a la división y combinación de los documentos transmisibles electrónicos se determinaran por el derecho sustantivo y que las modalidades en cuestión reflejaran la práctica vigente.

69. El Grupo de Trabajo acordó que, por el momento, no era necesario preparar una norma general sobre la participación del emisor del documento transmisible electrónico durante la circulación del documento.

3. Fin del ciclo vital de los documentos transmisibles electrónicos

70. Con respecto a la “presentación” de los documentos transmisibles electrónicos para su cumplimiento, se indicó que la presentación en el entorno electrónico planteaba problemas prácticos importantes debido a la lejanía y la posible falta de familiaridad entre las partes y se señaló la necesidad de abordar cuestiones relativas al cumplimiento parcial y a la negativa de la parte obligada a cumplir.

71. El Grupo de Trabajo convino en que había de prepararse una norma con el fin de lograr la equivalencia funcional con respecto a la distribución física de documentos en papel. Acordó además que esa norma no debía referirse a las consecuencias jurídicas de la presentación, que debían regularse mediante el derecho sustantivo.

72. En cuanto a la “conversión” de documentos transmisibles electrónicos, se afirmó que, debido a los diferentes grados de preparación de los distintos Estados y círculos empresariales, era esencial facilitar la convertibilidad, por ejemplo los conocimientos de embarque electrónicos utilizados a nivel transfronterizo, para lograr una aceptación y un uso más amplios de los documentos transmisibles electrónicos.

73. Se señaló que los efectos legales del documento o título que hubiera de convertirse, y la información contenida en ese documento o título, no debían modificarse, para que así se cumpliera el criterio de neutralidad respecto de los medios técnicos disponibles. Se convino, por tanto, en que la conversión no debía referirse a situaciones en las que se cancelara un documento o título y se emitiera uno nuevo, sino a aquellas en que simplemente se cambiara el soporte utilizado. También se subrayó que el documento o título en su forma original, una vez convertido, debería dejar de surtir efecto legal en esa forma original para impedir la posibilidad de que surgieran múltiples reclamaciones.

74. Se sugirió que solo debía permitirse la conversión de documentos en papel a documentos electrónicos, pues de esa forma se promovería en general un uso más amplio de los medios electrónicos. En respuesta, se argumentó que debía permitirse la conversión en ambos sentidos con el fin de reflejar las prácticas mercantiles vigentes y permitir el uso de documentos en papel por las partes que tuvieran acceso limitado a la tecnología de la información y las comunicaciones. Se afirmó que la imposibilidad de volver a convertir un documento electrónico a un documento en papel después de haber sido convertido a un formulario electrónico podría representar un obstáculo al momento de decidir convertir un documento en papel al formato electrónico. Se apoyó el enfoque más amplio y flexible.

75. Se preguntó si no habría que distinguir entre la cancelación de un documento electrónico tras su conversión y la cancelación del efecto legal del documento tras el cumplimiento de la obligación básica. Se respondió que cada caso debía recibir un tratamiento distinto, en particular porque la cancelación debida a la conversión no entrañaba la cancelación de la obligación básica. Se sugirió que debía elegirse cuidadosamente la terminología para evitar cualquier ambigüedad, por ejemplo, que podría hacerse referencia a una “sustitución” cuando se tratara de una conversión.

76. Se sugirió además que habría que tener en cuenta las cuestiones siguientes: i) si el documento o título tendría que incluir información sobre la conversión; ii) qué partes debían dar su consentimiento o participar de alguna otra manera en la conversión, y iii) si el documento o título sustituido podría restaurarse en determinadas circunstancias, como cuando no se hubiera creado el documento o título que había de sustituirlo o dicho documento o título se hubiera perdido. Se señaló que el derecho sustantivo no solía regular esas cuestiones.

77. Tras las correspondientes deliberaciones, se convino en que debía prepararse una norma general que previera la posibilidad de convertir documentos en papel en documentos transmisibles electrónicos y viceversa, teniendo en cuenta los diversos aspectos previamente mencionados.

78. Con respecto a la “cancelación”, se reiteró que debería elegirse cuidadosamente la terminología para evitar toda ambigüedad, en particular porque algunos términos podrían entrañar consecuencias legales. Se aclaró que no se trataba de la cancelación de la obligación básica, que era una cuestión de derecho

sustantivo, sino de las circunstancias por las cuales el documento transmisible electrónico dejaría de surtir efectos legales, por ejemplo, en caso de cumplimiento por la parte obligada. En ese contexto, se subrayó la necesidad de impedir que el documento siguiera circulando, lo que podría dar lugar a ulteriores reclamaciones, incluso tras el cumplimiento de la obligación.

79. Se aclaró también que determinar las circunstancias en las cuales los títulos o documentos transmisibles dejarían de surtir efectos legales era una cuestión de derecho sustantivo, razón por la cual podían diferir según el tipo de instrumento de que se tratara.

80. Se mencionó el artículo 9, párrafo 1 d) de las Reglas de Rotterdam, en que se hacía referencia a un mecanismo para dar confirmación de que se había realizado la entrega al tenedor o que el documento electrónico de transporte había perdido su eficacia o validez.

81. Durante el debate se plantearon las siguientes cuestiones: i) si el cumplimiento parcial por la parte obligada podría dar lugar a una cancelación parcial o a la enmienda del documento, o si daría lugar a la cancelación del documento existente y a la emisión de un nuevo documento, y ii) si era necesario lograr la equivalencia funcional de las anotaciones que indicaban la cancelación de un documento impreso. En cuanto a la forma de archivar el documento, se sugirió la posibilidad de que el artículo 10 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, relativo a la conservación de los mensajes de datos, se utilizara como punto de partida para el debate.

82. Tras las deliberaciones correspondientes, se convino en que debería prepararse una norma general para atender a la necesidad de reproducir de una manera funcionalmente equivalente las circunstancias en que un documento transferible impreso dejaría de surtir efectos legales.

C. Otras cuestiones relativas a los documentos transmisibles electrónicos

1. Terceros prestadores de servicios

83. El Grupo de Trabajo pasó a examinar las cuestiones jurídicas relativas a las terceras partes que prestan servicios para expedir y utilizar documentos transmisibles electrónicos, tales como los administradores de registros. En ese contexto, se indicó que había que distinguir entre los archivos y los proveedores de otros servicios.

84. Se indicó que la inclusión del tema en las normas que se preparasen podía llevar a que se favoreciera un determinado sistema, con lo que se violaría el principio de neutralidad de la tecnología y el sistema utilizados. A ese respecto se mencionaron las disposiciones sobre prestadores de servicios de certificación que figuraban en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas. En respuesta, se señaló que tal vez se podrían elaborar normas que abarcaran todas las terceras partes que prestaran servicios de gestión de documentos transmisibles electrónicos, sin hacer referencia expresa a ningún tipo de tecnología o sistema en concreto.

85. Se sugirió que la responsabilidad de los terceros era una cuestión que debía regularse mediante el derecho sustantivo o acuerdos contractuales y que los usuarios de los sistemas existentes recibían una protección adecuada mediante el seguro que cubría a los administradores de esos sistemas. Se afirmó además que, aunque tal vez se pudieran hallar algunos parámetros que pudieran servir de orientación para establecer la fiabilidad de los terceros prestadores de servicios, había que actuar con prudencia al abordar cuestiones de si era adecuada una regulación y en qué medida. Se especificó que no era necesario someter a las terceras partes a sistemas obligatorios de licencias ni de solución de controversias.

86. Por otra parte, se indicó que en algunas jurisdicciones, especialmente las de países de tradición jurídica romanista, los registros eran públicos y estaban sujetos a las normas establecidas por ley, así como a requisitos en materia de licencias. Se sugirió que ese enfoque era el más apropiado para fomentar la confianza en el comercio internacional, donde las partes se encontraban lejos unas de otras y a veces no se conocían. Se sugirió que debían elaborarse distintos tipos de registros para los diversos tipos de documentos transmisibles electrónicos, siguiendo el ejemplo sentado con los registros establecidos por el Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil (“Convenio de Ciudad del Cabo”) y sus protocolos. Se subrayó que dejar enteramente en manos del mercado el establecimiento de regímenes de responsabilidad respecto a dichos registros podía exponer a los operadores comerciales a riesgos excesivos.

2. Reconocimiento transfronterizo de documentos transmisibles electrónicos

87. Se reiteró la importancia de los aspectos transfronterizos del reconocimiento legal de los documentos transmisibles electrónicos. Se indicó que los aspectos transfronterizos eran particularmente comunes en el caso de los documentos transmisibles electrónicos utilizados en la industria del transporte marítimo.

88. Aunque se expresó la opinión de que para hacer posible la utilización a nivel transfronterizo de documentos transmisibles electrónicos se requería el examen de determinados aspectos, como las cuestiones de ejecución, no se pidió una labor de armonización más amplia. Se hizo referencia al artículo 12 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas como ejemplo de disposición destinada específicamente a permitir el reconocimiento transfronterizo.

89. En respuesta, se indicó que para posibilitar la utilización transfronteriza eficaz de documentos transmisibles electrónicos era indispensable que se abordaran no solo los aspectos concretos del funcionamiento de ese tipo de documentos, sino también el marco jurídico internacional más amplio aplicable a las comunicaciones electrónicas.

D. Labor futura

90. El Grupo de Trabajo procedió a realizar un debate preliminar sobre el posible resultado futuro de sus deliberaciones sobre los documentos transmisibles electrónicos.

91. A un nivel general, se indicó que el contenido de las normas que se habrían de preparar serviría de orientación a la hora de seleccionar la forma adecuada que

revestirían. Se agregó que el nivel de armonización jurídica que se considerase deseable sería también pertinente respecto de esa elección.

92. Habida cuenta de los progresos realizados, se sugirió que un resultado posible de la labor realizada podría concretarse en una ley modelo basada en los textos existentes de la CNUDMI y que a la vez los complementaría. Se explicó que una ley modelo facilitaría la flexibilidad a la hora de abordar las diferencias en los ordenamientos jurídicos sustantivos de los países. Se expresó cierto apoyo a la preparación de textos de orientación, por ejemplo una guía legislativa. Se mencionó también la posibilidad de plantearse en el futuro la posibilidad de preparar un instrumento de carácter más vinculante, de la índole de un tratado.

93. Se expresó amplio apoyo a la preparación de proyectos de disposiciones para su examen en el próximo período de sesiones del Grupo de Trabajo. Se agregó que esas disposiciones deberían presentarse en forma de una ley modelo, sin perjuicio de la decisión que el Grupo de Trabajo adoptara sobre la forma de su labor.

V. Asistencia técnica y coordinación

94. Se informó al Grupo de Trabajo de la entrada en vigor de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas el 1 de marzo de 2013, al pasar a ser partes Honduras, la República Dominicana y Singapur. Se indicó también que otros 16 Estados habían firmado la Convención. Destacando la importancia de la Convención para facilitar el uso de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional, el Grupo de Trabajo alentó a otros Estados a que consideraran la posibilidad de pasar a ser partes en la Convención y, en ese contexto, varios Estados expresaron su interés e informaron al Grupo de Trabajo que se estaban adelantando consultas internas y labor legislativa preparatorias.

95. Seguidamente se informó al Grupo de Trabajo de las actividades emprendidas para la promoción de los textos de la CNUDMI. En particular, se explicaron las iniciativas a nivel regional, y la consiguiente legislación promulgada (para más detalles, véase A/CN.9/753, párrs. 19 y 33 a 35). El Grupo de Trabajo expresó a la Secretaría su reconocimiento por la labor realizada en el ámbito de la asistencia técnica y puso de relieve la importancia que tenía esa labor en la promoción del cumplimiento del mandato de la CNUDMI. El Grupo de Trabajo tuvo la oportunidad de escuchar una ponencia sobre los aspectos jurídicos, tecnológicos y funcionales de las actuales iniciativas relativas a la utilización de las comunicaciones electrónicas en la Federación de Rusia, con miras a facilitar el reconocimiento transfronterizo a nivel regional e internacional.

96. Se informó luego al Grupo de Trabajo de la cooperación continua con diversas organizaciones en lo que se refiere a cuestiones jurídicas relativas a los servicios electrónicos de ventanilla única. El Grupo de Trabajo tomó nota de la resolución 68/3 aprobada por la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) que propiciaba el comercio sin soporte de papel y el reconocimiento transfronterizo de datos y documentos electrónicos para la facilitación, con carácter inclusivo y sostenible, del comercio intrarregional, en la cual se alienta a la adopción de normas internacionales existentes, como las que figuran en los textos de la CNUDMI, con el fin de favorecer la interoperabilidad. El Grupo de Trabajo también tomó nota de la publicación “Electronic Single Window Legal Issues: A Capacity-Building Guide”,

preparada conjuntamente por la Red de expertos de las Naciones Unidas para el comercio sin soporte de papel en Asia y el Pacífico (UNNEXT), la CESPAP y la Comisión Económica para Europa (CEPE). Se pidió a la Secretaría que continuara trabajando estrechamente con la CESPAP, en particular a través del Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico y en concreto sobre la aplicación de la resolución 68/3 de la CESPAP, así como con otras organizaciones pertinentes.

97. El Grupo de Trabajo tomó nota de una declaración de la secretaria de la OMA, en la cual señalaba la creciente importancia de los servicios de ventanilla única para facilitar el desarrollo del comercio, en particular para los países en desarrollo y los países menos adelantados, y acogió con agrado la contribución de la CNUDMI en el establecimiento de las normas jurídicas conexas. En esa declaración la secretaria de la OMA también observó que los documentos transmisibles electrónicos eran un elemento clave de la cadena de suministros sin papel y destacó la importancia de la disponibilidad de esos documentos para aumentar la calidad de los datos que se envían a los servicios de ventanilla única, haciendo así posibles los intercambios electrónicos continuos entre las entidades privadas y públicas.

98. Respecto de las cuestiones jurídicas concernientes a la gestión de la identidad, el Grupo de Trabajo escuchó un resumen del documento de trabajo presentado por el grupo de tareas *Identity Management Legal Task Force* de la *American Bar Association* (A/CN.9/WG.IV/WP.120), que ofrecía una visión general sobre la gestión de la identidad digital, su posible función en el comercio electrónico y las cuestiones jurídicas pertinentes. Se hizo referencia en particular al tratamiento jurídico adecuado de los riesgos asociados con los sistemas de gestión de la identidad en relación con la responsabilidad de los terceros prestadores de servicios.

99. A continuación, se informó al Grupo de Trabajo de la cooperación de la Secretaría con la CEPE y el Centro de las Naciones Unidas de Facilitación del Comercio y las transacciones electrónicas (UN/CEFACT). Se señaló que la Secretaría estaba participando en dos proyectos: i) la revisión de la recomendación 14 del CEFACT que trata sobre la autenticación de documentos comerciales por medios distintos de la firma; y ii) la preparación de la recomendación 36 del CEFACT sobre la interoperabilidad de la ventanilla única, cuyo objetivo es complementar las recomendaciones 33 y 35 ya existentes sobre este tema.

100. Por último, se informó al Grupo de Trabajo de una propuesta, de la Comisión Europea formulada en junio de 2012, de un “Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior”. Se señaló que la Secretaría había participado en el proceso de consultas para garantizar un enfoque coordinado sobre la cuestión.

VI. Otros asuntos

101. Se informó al Grupo de Trabajo que el 47º período de sesiones del Grupo de Trabajo se celebrará en Nueva York, del 13 al 17 de mayo de 2013.

**B. Nota de la Secretaría sobre cuestiones jurídicas relativas a la
utilización de documentos transmisibles electrónicos, presentada
al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico
en su 46º período de sesiones**

(A/CN.9/WG.IV/WP.118 y Add.1)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1
II. Alcance de la labor	2-25
A. Documentos transmisibles electrónicos	4-18
B. Gestión de los documentos transmisibles electrónicos	19-25
III. Cuestiones jurídicas relativas a los documentos transmisibles electrónicos	26-70
A. Creación y comunicación de documentos transmisibles electrónicos	29-70
1. Singularidad	39-50
2. Control del documento transmisible electrónico	51-61
3. Identificación del emisor y del primer tenedor	62-70

I. Introducción

1. En la presente nota se proporciona información general sobre las principales cuestiones jurídicas relativas a la creación, el empleo y la transmisión de documentos transmisibles electrónicos. No se procura abordar en ella las cuestiones jurídicas sustantivas que serían aplicables independientemente del medio empleado.

II. Alcance de la labor

2. En cuanto al alcance de la labor, el Grupo de Trabajo acordó, en su 45º período de sesiones, que se adoptara un enfoque amplio, teniendo en cuenta todos los tipos posibles de documentos transmisibles electrónicos, dejando abierta la posibilidad, al mismo tiempo, de hacer distinciones en el tratamiento de esos documentos electrónicos, cuando fuera conveniente¹. Sin embargo, en el 45º período de sesiones de la Comisión (25 de junio a 6 de julio de 2012, Nueva York), se señaló la conveniencia de determinar tipos concretos de documentos transmisibles electrónicos o cuestiones específicas relativas a estos, así como la de centrarse en ellos².

¹ A/CN.9/737, párr. 22.

² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17)*, párr. 83.

3. Tomando nota de la decisión y la sugerencia mencionadas *supra*, quizá el Grupo de Trabajo desee examinar el alcance de labor en una etapa posterior, una vez que haya podido determinar cuáles son las cuestiones pertinentes y haya tenido oportunidad de abordarlas. El Grupo de Trabajo quizá desee considerar también las necesidades concretas de los sectores pertinentes.

A. Documentos transmisibles electrónicos

4. La expresión “documento transmisible electrónico” se refiere, en general, al equivalente electrónico tanto de un título transferible como de un documento de titularidad. En inglés se habla de “*record*” electrónico transferible y no de “*document*” para subrayar su carácter digital.

5. “Título transferible” se refiere generalmente a un título financiero que puede contener una promesa incondicional de pagar una cantidad fija de dinero al tenedor del título, o una orden para que un tercero haga el pago a dicho tenedor. Como ejemplos de títulos transmisibles cabe mencionar los pagarés, las letras de cambio, los cheques y los certificados de depósito. La expresión “documento de titularidad” se refiere, en general, a un documento que, en el curso ordinario de los negocios o de la financiación, constituye una prueba fehaciente de que la persona que está en su posesión tiene derecho a recibir y conservar el documento y las mercancías a que se refiera y a enajenarlos, a reserva de las excepciones que quepa oponer a la ejecución del documento. Como ejemplo de documento de titularidad cabe mencionar los conocimientos de embarque y los resguardos de almacén³.

6. Una característica fundamental de los títulos transmisibles y los documentos de titularidad es la posibilidad de “transmitir” el derecho a la ejecución de la obligación consignada en el título o documento con la transmisión física del soporte de papel en que se ha reproducido el título o documento. Otra característica común, por lo menos en algunos ordenamientos jurídicos, es la de que los títulos o documentos consignados en papel se emiten normalmente de manera individual y no en masa⁴.

7. Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre los diversos ordenamientos jurídicos en cuanto al tratamiento de los títulos transmisibles y los documentos de titularidad. Así, por ejemplo, la ley puede limitar la libertad de las partes en la elaboración de dichos títulos de manera que, para ser válidos, deben ajustarse a modelos definidos previamente (norma *numerus clausus*).

8. Si bien los términos “transferible” y “negociable” se han usado conjuntamente en venerables precedentes de la jurisprudencia⁵, su empleo ha dado lugar posteriormente a una considerable controversia sobre la distinción entre ambos⁶. En general cabe afirmar que la “transferibilidad” se refiere a la posibilidad de transmitir el derecho a la ejecución junto con la posesión del título o documento, en tanto que “negociabilidad” otorga al tenedor del título o documento un derecho más válido a

³ A/CN.9/WG.IV/WP.115, párr. 3.

⁴ A/CN.9/WG.IV/WP.116, Sección 1 a).

⁵ *Lickbarrow v. Mason* (1794) 5T. R. 683, pág. 685.

⁶ Para un resumen del debate sobre el empleo de los términos “transmisible” y “negociable” y su distinción, véase “The bill of lading as a document of title”, *Journal of International Trade Law and Policy*, Vol. 10 No. 3, 2011, pág. 255, págs. 262 y 263.

la ejecución que el del autor de la transmisión, en la medida en que la ley limita las excepciones que pueden oponerse a la ejecución del documento negociable ante el portador de buena fe del documento negociable⁷.

9. Con todo, si un título o un documento es “transferible” o “negociable” depende del derecho sustantivo aplicable. En épocas pasadas se habían preparado textos uniformes para abordar las cuestiones sustantivas, a saber: i) el Convenio por el que se establece una Ley uniforme referente a las letras de cambio y pagarés a la orden (Ginebra, 1930)⁸, ii) el Convenio por el que se establece una Ley uniforme en materia de cheques (Ginebra, 1931)⁹ y iii) la Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagarés Internacionales (Nueva York, 1988)¹⁰. Cabe observar además que el concepto de negociabilidad y, en particular, su pertinencia para el empleo de documentos electrónicos ha sido cuestionado¹¹.

10. La legislación existente relativa a los documentos transmisibles electrónicos varía en cuanto al ámbito de aplicación y el enfoque. En algunos casos, se han adoptado disposiciones que permiten el uso general de los documentos transmisibles electrónicos, por lo menos en teoría. En otros casos, se ha adoptado un enfoque sectorial que trata, en particular, del uso de los documentos transmisibles electrónicos en los sectores financiero y del transporte.

11. Las siguientes leyes tratan de las operaciones financieras: i) la Ley del Japón sobre Créditos Monetarios Registrados Electrónicamente (Ley Núm. 102 de 2007, la “ERMCA”)¹²; ii) la Ley sobre Emisión y Negociación de Letras de Cambio y Pagarés Electrónicos (Ley Núm. 7197, de 22 de marzo de 2004, y enmiendas subsiguientes) de la República de Corea; iii) el artículo 7 (Documentos de Titularidad) del Código de Comercio Uniforme de los Estados Unidos de América; iv) el artículo 9 (Operaciones Garantizadas) del Código de Comercio Uniforme; v) el artículo 16 de la Ley Uniforme de Operaciones Electrónicas¹³ (UETA) de los Estados Unidos; y vi) el título 7 (Agricultura) del Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos de América, en particular la parte relativa a los resguardos de almacén electrónicos (Parte 735: Reglamento de la Ley de Almacenes de los Estados Unidos).

12. Ha habido otras novedades importantes, a saber: i) en Australia, tras la revisión de la Ley sobre letras de cambio de 1909, en julio de 2003, que tenía por objeto responder a solicitudes del sector comercial de que se promulgaran leyes que permitiesen la emisión de letras de cambios y de pagarés sin soporte físico, hubo un examen a fondo del posible uso de documentos transmisibles electrónicos¹⁴. En

⁷ A/CN.8/737, párrs. 51 y 53.

⁸ Sociedad de las Naciones, *Treaty Series*, vol. 143, pág. 257.

⁹ Sociedad de las Naciones, *Treaty Series*, vol. 143, pág. 355.

¹⁰ Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.95.V.16 (tratado que no ha entrado en vigor).

¹¹ Ronald J. Mann, *Searching for Negotiability in Payment and Credit Systems*, 44 *UCLA L. Rev.* (1997).

¹² La ERMCA entró en vigor en el Japón el 1 de diciembre de 2008, con el fin de facilitar las actividades financieras de las empresas. Los créditos monetarios registrados electrónicamente se refieren a los créditos monetarios que, para poder ser cedidos, deben constar electrónicamente en el registro.

¹³ La UETA fue elaborada por la Conferencia Nacional de Comisarios de Leyes Uniformes de los Estados, Estados Unidos de América, y se ha promulgado en 47 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

¹⁴ Grupo de Trabajo de funcionarios, examen de la política nacional sobre la competencia: Ley sobre

cuanto a las opciones de reforma, se recomendó un enfoque legislativo basado en la equivalencia funcional; ii) en el Brasil, el artículo 889 del Código Civil brasileño (Ley núm. 10.406, de 10 de enero de 2002), que trata de los documentos de titularidad (Dos Títulos de Crédito) incluye una disposición aparte dedicada a los títulos generados electrónicamente¹⁵; y iii) en China, se aprobaron en 2009 las Normas Administrativas para las Operaciones con Letras de Cambio Comerciales Electrónicas y las Normas Administrativas para el Sistema Electrónico de Cheques Comerciales¹⁶ y en octubre de 2009 el Sistema Electrónico de Cheques Comerciales fue llevado a la práctica por el Banco Popular de China, prestando apoyo así al desarrollo de las operaciones con cheques comerciales y facilitando la reducción de los gastos y riesgos de procesamiento.

13. El empleo de documentos transmisibles electrónicos en los países en desarrollo se centra en los resguardos de almacén electrónicos, que se consideran un medio eficaz de proporcionar financiación a los agricultores, contribuyendo así, por tanto, a la seguridad alimentaria sobre una base más previsible y sostenible¹⁷. El artículo 11 de la Ley (de desarrollo y reglamentación) de almacenes, de 2007, de la India, prevé explícitamente el empleo de resguardos de almacén en formato electrónico¹⁸. Sin embargo, el artículo 2 del Reglamento de la Dirección de desarrollo y reglamentación de almacenes (resguardos de almacén negociables), de 2011, excluye actualmente de su ámbito de aplicación los resguardos de almacén negociables en formato electrónico¹⁹. En el Brasil, el Certificado de Depósito de la Agroindustria (CDA) y la Garantía de la Agroindustria (GA), que pueden

letras de cambio de 1909, julio de 2003, que puede consultarse en: <http://archive.treasury.gov.au/documents/688/PDF/Final%20Bills%20of%20Exchange%20Act%20Review.pdf>.

¹⁵ En el párrafo 3 del artículo 889 se dispone que el título puede ser emitido a partir de los caracteres creados por una computadora o un medio técnico equivalente, y figurar en las constancias del emisor, siempre que se ajuste a los requisitos mínimos establecidos en ese artículo. Sin embargo, en cuanto a la interpretación de ese párrafo, algunos expertos han advertido que no permite necesariamente la emisión de documentos transmisibles electrónicos, sino que simplemente reconoce que los títulos negociables pueden haberse preparado originalmente en forma electrónica, para luego “materializarse” en formato no electrónico. Esta interpretación se basa en la definición enunciada en el artículo 887 de Código Civil brasileño, que denomina al título “documento”, término que en general se asocia con los medios no electrónicos.

¹⁶ Véase Annual Report of the PBC 2009, págs. 62, 68 y 78. Puede consultarse en http://www.pbc.gov.cn/image_public/UserFiles/english/upload/File/Annual%20Report%202009.pdf.

¹⁷ Henry Gabriel, Warehouse Receipts and Securitization in Agricultural Finance, *Uniform Law Review/Revue de droit uniforme* 2012, pág. 369

¹⁸ La ley entró en vigor el 25 de octubre de 2010 (puede consultarse el texto completo de la Ley en http://dfpd.nic.in/fcamin/sites/default/files/userfiles/Warehouse_Act_2007.pdf). Aparte de disponer la negociabilidad de los resguardos de almacén, la Ley prescribe la forma que ha de adoptar el registro de los almacenes y la emisión de resguardos de almacén negociables, incluso en formato electrónico, y prescribe el establecimiento de la Dirección de desarrollo y reglamentación de almacenes, órgano regulador creado en virtud de la Ley. Se ha predicho que la implantación del sistema de resguardos de almacén negociables no solo ayudará a los agricultores a obtener mayores facilidades de crédito y evitar las ventas a precios desfavorables, sino que también ofrecerá protección a las instituciones financieras al mitigar los riesgos inherentes al otorgamiento de crédito a los agricultores. El uso de la producción agrícola como prenda o garantía con el respaldo jurídico de los resguardos de almacén negociables hará que aumente la corriente de crédito hacia las zonas rurales, se reduzca el costo del crédito y se estimulen las actividades conexas como la estandarización, la clasificación según la calidad, el embalaje y el seguro, así como el desarrollo de una cadena de almacenes de calidad (véase <http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=66574>).

¹⁹ Puede consultarse el texto completo de la reglamentación en <http://wdra.nic.in/>.

presentarse en formato electrónico, se han desarrollado en el sector agrícola a fin de comercializar las existencias depositadas en almacenes²⁰.

14. El desarrollo de sistemas de resguardos de almacén se ha convertido en un importante medio de mejorar el rendimiento de los sistemas de comercialización agropecuaria en África, y los resguardos de almacén electrónicos se están popularizando en ciertos Estados africanos. La Proclamación Núm. 550/2007 de creación de la bolsa de productos básicos de Etiopía (Proclamación para el establecimiento de una bolsa de productos básicos de Etiopía) prevé un sistema de resguardos de almacén electrónicos²¹ y en Ghana, Sudáfrica y Uganda existen regímenes similares. Por ejemplo, en 2004, la Bolsa de Futuros Sudafricana (SAFEX) anunció que aceptaría resguardos de almacén tanto electrónicos como consignados en papel para la liquidación de contratos de futuros²².

15. Las siguientes leyes tratan del empleo de documentos transmisibles electrónicos en el sector del transporte: i) el artículo 862 de la Ley Comercial revisada, que incorpora legislación que permite el empleo de conocimientos de embarque electrónicos, de la República de Corea (“Legislación de la República de Corea sobre conocimientos de embarque electrónicos”)²³ y ii) el artículo 7 (Documentos de titularidad) del Código de Comercio Uniforme. Son pertinentes también i) los artículos 16 (Medidas relacionadas con los contratos de transporte de mercancías) y 17 (Documentos de transporte) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico de 1996 (Ley Modelo sobre Comercio Electrónico)²⁴; y ii) el capítulo 3 y otras disposiciones pertinentes del Convenio de las Naciones

²⁰ El CDA y la GA, creados por Ley núm. 11.076/04, son instrumentos de crédito ligados a la producción depositada en los almacenes. El CDA representa la promesa de entrega de los bienes depositados, en tanto que la GA pone como garantía de pago las mercaderías descritas en el CDA. Esos instrumentos son gemelos en el sentido de que se expiden en el mismo momento y se refieren a las mismas mercancías. Son emitidos por el depositario de los bienes, que pertenecen a los propietarios de las existencias o a los sucesivos compradores de esos instrumentos. La garantía debe ser registrada y depositada en poder de una entidad autorizada por el Banco Central. A partir de ese momento, la negociación de los títulos se vuelve forzosamente electrónica. La GA permite al titular ofrecer el producto como garantía para obtener un préstamo bancario, en tanto que el CDA permite al titular vender las mercancías, sin que tenga que pagar ningún impuesto hasta que el propietario de los títulos, en calidad de agente económico, manifieste el deseo en efecto de utilizar el producto almacenado para su elaboración o venta.

²¹ Puede consultarse el texto completo de la proclamación en www.ecx.com.et/downloads/rules/ecexproclamation.pdf.

²² Sarel F. du Toit, *Reflections on Bills of Lading and Silo Receipts used in the South African Futures Market*, 2 *Journal of International Commercial Law and Technology* 3 (2007) 105; Gideon Onumah, *Promoting Agricultural Commodity Exchanges in Ghana and Nigeria: A Review Report*, Report to UNCTAD, págs. 8 y 9; Gideon Onumah, *Implementing Warehouse Receipt System in Africa – Potential and Challenges*, preparado para el Cuarto Simposio Africano de Política de Programas de Mercados (6 y 7 de septiembre de 2010, Malawi); el texto puede consultarse en www.aec.msu.edu/fs2/aamp/sept_2010/aamp_lilongwe-onumah-warehouse_receipt_systems.pdf; Ghana Grains Council Warehouse Receipt System Rules and Regulations, artículo 26(3): “GGC Warehouse Receipts shall be paper or electronic documents”.

²³ /CN.9/692, párrs. 26 a 47.

²⁴ Publicación de las Naciones Unidas, Núm. de venta S.99.V.4. Los artículos 16 y 17 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico han sido incorporados a leyes nacionales, por ejemplo, los artículos 26 y 27 de la Ley 527 (1999) de Colombia, y los artículos 31 y 32 del Decreto Núm. 47 de Guatemala (2008). Sin embargo, estas disposiciones no parecen haber encontrado aplicación en la práctica.

Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo de 2008 (“Reglas de Rotterdam”)²⁵.

16. La Asamblea Legislativa de Ontario introdujo la Ley de Enmienda de Comercio Electrónico, 2012 (“Proyecto de Ley 96”) en mayo de 2012 para facilitar el empleo de medios electrónicos en las operaciones de bienes raíces²⁶. Si se aprueba, el Proyecto de ley 96 enmendará la Ley de Comercio Electrónico, 2000, de Ontario (S.O. 2000, capítulo 17: ley inspirada por la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, 1996)²⁷ y permitirá el empleo de los documentos transmisibles electrónicos equivalentes a documentos de titularidad, aunque no el de los equivalentes a títulos negociables²⁸.

17. No obstante los enfoques sectoriales que se mencionan *supra*, la adopción de una definición más amplia de documento transmisible electrónico para su examen por el Grupo de Trabajo permitiría un enfoque también más amplio de su labor. Un punto de partida útil podría ser el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, de 2005 (Convención de Comunicaciones Electrónicas)²⁹, que menciona los tipos de títulos o documentos transmisibles excluidos del ámbito de aplicación de la Convención. Según este enfoque, los documentos transmisibles electrónicos pueden referirse al “equivalente electrónico de las letras de cambio, pagarés, cartas de porte, conocimientos de embarque o resguardos de almacén, [o cualquier] documento o título transferible que faculte a su portador o beneficiario para reclamar la entrega de las mercancías o el pago de una suma de dinero”.

18. Además, el hecho de que los pagos electrónicos y el dinero electrónico no sean tratados, en general, dentro del ámbito de aplicación mencionado *supra*, podría exigir un examen más a fondo puesto que, para los fines prácticos y operacionales, pueden estar correlacionados con los documentos transmisibles electrónicos.

B. Gestión de los documentos transmisibles electrónicos

19. Actualmente existen por lo menos dos sistemas para la gestión de los documentos transmisibles electrónicos. Uno de ellos, el más difundido en la práctica, se basa en el uso de registros electrónicos (“sistema de registro”). El otro se basa en el uso de claves o símbolos electrónicos (*tokens*), incorporados en el documento transmisible electrónico (“sistema de símbolo”)³⁰.

20. Como su nombre lo indica, el sistema de registro se basa en el establecimiento de un registro que contiene información sobre los documentos transmisibles electrónicos. De manera análoga a lo que sucede con los registros establecidos para la cesión de titularidades o derechos de propiedad, el registro indica la identidad del propietario del documento transmisible electrónico y la transmisión del documento

²⁵ Publicación de las Naciones Unidas, Núm. de venta S.09.V.9.

²⁶ Puede consultarse en www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=en&Intranet=&BillID=2644.

²⁷ Disponible en www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_00e17_e.htm#BK37.

²⁸ El párrafo 5 del artículo 31 1), de la Ley de Comercio Electrónico dispone que la Ley no es aplicable a los títulos negociables y el proyecto de Ley 96 no contiene ninguna propuesta que enmiende ese párrafo.

²⁹ Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.07.V.2.

³⁰ A/CN.9/WG.IV/WP.116, sección 3.

transmisble electrónico queda reflejada en el registro. Este tipo de sistema de registro satisface el requisito del control (véanse los párrafos 51 a 61 *infra*) al asegurar la identificación de un único titular del documento y de los derechos que incorpora en cualquier momento.

21. El sistema de símbolo puede describirse como un sistema más parecido, en funcionamiento, al sistema de los documentos de papel. Se basa en la identificación del documento original y único que puede ser reconocido como tal mediante software o tecnología y puede por tanto transmitirse de un sistema de información a otro sin que pierda ninguna de las cualidades antedichas. De este modo, es posible duplicar en el entorno electrónico el enfoque adoptado en el entorno de papel, puesto que la transmisión de un documento transmisble electrónico supone la transmisión del propio documento (o del control sobre el documento).

22. En ambos sistemas, la determinación de la existencia del documento transmisble electrónico, sus cualidades y sus efectos, así como su propiedad y transmisión, se basa en el intercambio de información. Y también en ambos sistemas, para que un documento transmisble electrónico (reconocido como original y auténtico) sea transferido, es precisa el traspaso del control sobre ese documento.

23. Si bien es cierto que debería adoptarse, en la medida de lo posible, un enfoque neutral en cuanto al sistema, varias de las disposiciones que se mencionan más adelante se refieren al funcionamiento de sistemas de registro. Por consiguiente, la preparación de disposiciones específicas para dichos sistemas sería conveniente pero siempre que se tenga presente el principio de la neutralidad tecnológica.

24. Con respecto a los sistemas de registro, habría que abordar las siguientes cuestiones: i) si han de funcionar a nivel nacional o internacional³¹; ii) si el registro estará concebido para dar cabida solo a determinados tipos de documentos transmisbles electrónicos o para acoger, en cambio, múltiples tipos³²; y iii) si un sistema de registro que adopte una tecnología específica podrá dar cabida a todos los tipos de documentos transmisbles electrónicos y funcionar en Estados que disponen de distintos niveles de tecnología de la información y las comunicaciones³³.

25. Por lo que se refiere a esas cuestiones, los ejemplos existentes de registros nacionales pertinentes demuestran que cada registro se ajusta a un solo tipo de documento transmisble electrónico. En algunos casos, puede existir más de un registro incluso para el mismo tipo de documento transmisble electrónico lo cual, por ejemplo, sucede en el caso de los créditos monetarios registrados electrónicamente en el Japón. Sin embargo, no debe descartarse por eso la posibilidad de diseñar un registro electrónico capaz de gestionar múltiples tipos de documentos transmisbles electrónicos.

³¹ A/CN.9/737, párr. 72.

³² *Ibid.*, párr. 73.

³³ *Ibid.*, párr. 74.

III. Cuestiones jurídicas relativas a los documentos transmisibles electrónicos

26. Actualmente no existe un marco jurídico internacionalmente aceptado, generalizado y armonizado para abordar las diversas cuestiones que se plantean en el uso de títulos transmisibles o documentos de titularidad (aparte de los textos mencionados *supra* en el párrafo 9), incluido el empleo de sus equivalentes electrónicos, los documentos transmisibles electrónicos³⁴.

27. Los marcos jurídicos nacionales son necesarios para permitir y facilitar el empleo de documentos transmisibles electrónicos y generar confianza en el usuario. La falta de disposiciones legislativas ha impedido el desarrollo de la práctica en esta esfera³⁵.

28. En la sección que sigue a continuación se examinan las dificultades y los obstáculos que crea el empleo de documentos transmisibles electrónicos, que habría que abordar en un marco jurídico internacional o nacional para los documentos transmisibles electrónicos. Se proporciona también información general sobre el ciclo vital de dichos documentos y diversos métodos para la identificación del tenedor.

A. Creación y comunicación de documentos transmisibles electrónicos

29. En un entorno de documentos de papel, los títulos transmisibles y los documentos de titularidad pueden ser emitidos directamente por el emisor. Sin embargo, las modalidades de la comunicación³⁶ de su equivalente electrónico dependerían del sistema elegido. En tanto que los documentos transmisibles electrónicos pueden ser comunicados directamente por el emisor en el sistema de símbolo, los sistemas de registro exigirían la intervención de un tercero, el administrador del registro. Por consiguiente, el emisor tendría que presentar una solicitud al administrador del registro para que se comunique el documento transmisible electrónico.

30. Por ejemplo, con arreglo al artículo 9-105 (Control de valores mobiliarios electrónicos) del Código de Comercio Uniforme, se crea un valor mobiliario electrónico (*electronic chattel paper*) cuando la parte garantizada transmite un ejemplar fehaciente del valor mobiliario electrónico al custodio designado (por ejemplo, el administrador del registro). El deudor no crea el documento transmisible electrónico directamente, si bien su consentimiento es necesario para el empleo de medios electrónicos.

31. La formulación de una solicitud de que se comunique un documento transmisible electrónico puede constituir una obligación para el emisor. Por

³⁴ *Ibid.*, párr. 14.

³⁵ *Ibid.*, párr. 46.

³⁶ Se utiliza el término “comunicación” de un documento transmisible electrónico para designar el paso técnico de poner el documento electrónico en circulación, en tanto que los términos “emisión” y “emisor” se utilizan con el significado ya establecido en el derecho sustantivo aplicable. El Grupo de Trabajo quizá desee considerar si desea seguir usando el término “comunicación” para referirse a los documentos transmisibles electrónicos.

ejemplo, con arreglo al artículo 35 de las Reglas de Rotterdam, el cargador puede tener derecho a recibir del porteador un documento de transporte electrónico negociable en cuyo caso, si se adopta el sistema de registro, el porteador estará obligado a pedir al administrador del registro que se comunique ese documento de transporte electrónico negociable.

32. Este enfoque se ha adoptado en las leyes sobre conocimientos de embarque electrónicos de la República de Corea, que ha optado por un sistema de registro³⁷. Con arreglo a esa legislación, el porteador debe dirigir una solicitud al administrador del registro para que ponga en circulación un conocimiento de embarque electrónico y esa solicitud constituye, al mismo tiempo, la autorización para emitir un conocimiento de embarque electrónico.

33. En el artículo 15 de la ERMCA se dispone que los derechos relativos a los créditos monetarios registrados electrónicamente se adquieren dejando constancia de ellos en el registro. Para hacerlo, tanto el deudor (es decir, el deudor contra el cual se puede ejercitar el derecho registrado electrónicamente) como el acreedor (es decir, el titular del derecho monetario registrado electrónicamente) tienen que dirigir la solicitud al registro³⁸ y el registro genera el documento³⁹. Esto significa que es la generación de un documento, y no la manifestación de intención, la condición necesaria para la creación de créditos monetarios registrados electrónicamente.

34. En cuanto al contenido del documento transmisible electrónico (es decir, la información que contiene), según una norma general el documento contendrá la misma información sustantiva que su equivalente de papel. En términos generales, el exigir más información sustantiva en el caso de los documentos transmisibles electrónicos sería contrario al principio de no discriminación contra las comunicaciones electrónicas. Se pueden incorporar condiciones en el documento transmisible electrónico por remisión, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 5 *bis* de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico.

35. Sin embargo, hay casos en que puede omitirse cierta información en los documentos de papel, pero no en el documento transmisible electrónico. Por ejemplo, en la República de Corea se permite la emisión de letras de cambio en blanco si el documento está consignado en papel⁴⁰, pero se prohíbe en el formato electrónico⁴¹.

36. Cierta información puede figurar en un documento transmisible electrónico, pero no en su contraparte de papel debido a su naturaleza electrónica. Si bien es cierto que parte de esa información puede ser solo de carácter técnico, el consentimiento de las partes en cuanto al empleo del formato electrónico es un elemento sustantivo. De hecho, la ley puede permitir un acuerdo general sobre el uso de medios electrónicos o bien puede requerir el consentimiento específico en cuanto a la emisión de cada documento transmisible electrónico.

37. En algunos casos puede disponerse de información adicional solo en el documento transmisible electrónico debido a su carácter dinámico, a diferencia del

³⁷ A/CN.9/692, párrs. 30 a 32.

³⁸ Artículo 5 1) y 7 de ERMCA.

³⁹ Artículo 7 1) de ERMCA.

⁴⁰ Artículo 10 de la Ley sobre letras de cambio y pagarés núm. 1001 de 1962 y enmiendas subsiguientes.

⁴¹ El párrafo 6 del artículo 6 sobre la ley relativa a la emisión y negociación de pagarés electrónicos.

carácter estático de los documentos de papel. Por ejemplo, la ubicación de una embarcación en un momento dado puede ser pertinente para ciertos documentos comerciales y puede verificarse mediante sistemas automáticos capaces de localizar y rastrear la embarcación.

38. La información contenida en el documento transmisible electrónico puede utilizarse con fines distintos de la gestión del documento. Por ejemplo, los conocimientos de embarque electrónicos pueden utilizarse para presentar información al servicio nacional de ventanilla única electrónica, de conformidad con un modelo que actualmente se está ensayando en la República de Corea. Además, la información contenida en los títulos financieros puede tomarse globalmente para vigilar el riesgo bancario, y la “desmaterialización” del título financiero podría simplificar la reunión de los datos. En el párrafo 1 del artículo 87 de la ERMCA se dispone que las partes interesadas en el documento pueden pedir la divulgación de los datos que contiene. Además, el párrafo 2 de ese artículo permite el uso de los datos por terceros que no sean las partes interesadas siempre que los que solicitaron la generación del documento hayan estado de acuerdo en ello en el momento de formular la solicitud. Por ejemplo, los organismos de calificación crediticia o los inversionistas podrían formular solicitudes de divulgación de los datos del documento con arreglo a esta disposición.

1. Singularidad

39. Una cuestión particularmente pertinente para los documentos transmisibles electrónicos es la necesidad de satisfacer el equivalente funcional del concepto de singularidad de los documentos de papel. Se garantiza la singularidad de los títulos transmisibles y los documentos de titularidad a fin de impedir la circulación de documentos múltiples relacionados con el mismo derecho, lo cual puede dar por resultado el pago de una suma de dinero o la entrega de mercancías a una parte que no tiene derecho a ese pago ni a esa entrega.

40. La singularidad es un requisito que debería satisfacerse independientemente de la circulación efectiva del documento transmisible electrónico. De hecho, la emisión de múltiples documentos transmisibles electrónicos y la presentación de todos ellos al deudor por el primer tenedor expondrían igualmente al deudor a múltiples demandas de cumplimiento y la posibilidad de pago o entrega a una parte que no tiene derecho a ello.

41. Se ha observado con frecuencia que las inquietudes relativas a la garantía de la singularidad provienen del hecho de que un documento electrónico pueda ser copiado, en general, de manera que crea un duplicado idéntico al original y, por tanto, resulta indistinguible de este⁴². Además, las copias electrónicas pueden producirse en gran cantidad, en poco tiempo y a un costo limitado.

42. Sin embargo, cabe observar también que los documentos de papel no siempre ofrecen una garantía absoluta de singularidad. En realidad, puede no resultar posible encontrar una sola definición legislativa de singularidad. Además, el fraude basado en la duplicación ilegal de esos documentos es común⁴³. Pueden presentarse otros

⁴² A/CN.9/WG.IV/WP.115, párrs. 14 y 36.

⁴³ Por ejemplo, Clayton P. Gillette & Steven D. Walt, *Uniformity and Diversity in Payment Systems*, 83 Chicago-Kent Law Review 499 (2008), en 529, comparan la seguridad de dos sistemas de

problemas debido a las dificultades con que se tropieza para reunir un juego completo de documentos de papel para la presentación si se ha emitido más de un original. Por consiguiente, el establecimiento de una norma más alta de singularidad para los documentos transmisibles electrónicos a fin de aquietar las preocupaciones mencionadas por la posibilidad de fraude y maximizar la seguridad podría ser discriminatorio cuando se compara con el nivel de seguridad ofrecido por su equivalente de papel y puede, en última instancia, obstaculizar la difusión de los documentos transmisibles electrónicos en la práctica comercial.

43. Actualmente se dispone de dos métodos para satisfacer el equivalente funcional de la singularidad en un entorno electrónico. Uno de ellos es el basado en la singularidad técnica, es decir, la seguridad de que el documento electrónico no pueda reproducirse. Sin embargo, esta garantía puede no ser factible tecnológicamente para los documentos electrónicos, así como no lo es tampoco para los documentos de papel. En teoría, quizá sea técnicamente posible crear un documento electrónico verdaderamente único que no pueda copiarse (por lo menos sin que la copia pueda distinguirse como tal) y que pueda transmitirse. Llegado el caso de que exista y tenga una amplia difusión una tecnología capaz de garantizar la singularidad de un documento electrónico y de permitir su transmisión, ello ofrecería una base para conferir carácter único al documento electrónico. Entre las tecnologías potencialmente pertinentes para lograr la singularidad técnica podrían incluirse los identificadores digitales de objetos electrónicos (DOI) y la gestión de derechos de acceso digital (DRM)⁴⁴.

44. El otro enfoque se basa en la designación de un ejemplar fehaciente que proporcione una garantía suficiente de singularidad. La designación de un ejemplar fehaciente de un documento transmisible electrónico puede responder a las preocupaciones relacionadas con la integridad del documento (por ejemplo, al establecer “qué” es aquello en que tiene interés el titular) sin necesidad de una garantía absoluta de la existencia de un documento único. Este enfoque es el que está actualmente más difundido tanto en las legislaciones neutrales con respecto al sistema seguido como en las legislaciones que utilizan el sistema de registro⁴⁵. La designación de un ejemplar fehaciente del documento transmisible electrónico puede llevarse a cabo por distintos métodos, es decir, según que esté archivado en un sistema seguro y específico o que se base en un contenido o localidad verificables⁴⁶. Esta designación puede realizarse en el sistema de registro o en el de símbolo, según cuál sea la tecnología utilizada⁴⁷.

45. Como ya se dijo, uno de los métodos para la designación de un ejemplar fehaciente se basa en la existencia de un sistema seguro y específico, es decir, un registro electrónico, en que el administrador del registro asigna un número de

pago concurrentes: las operaciones con cheques de papel y con tarjetas de débito. Estos autores llegan a la conclusión de que existe una proporción de 6 a 1 de los fraudes respectivos, es decir que las pérdidas debidas al fraude en operaciones con cheques son seis veces más frecuentes que las causadas por las operaciones fraudulentas de tarjetas de débito, según los datos recogidos en 2004. El valor medio de las pérdidas fue también considerablemente mayor en el caso de las operaciones con cheques que en el de las realizadas con tarjetas de débito.

⁴⁴ A/CN.9/WG.IV/WP.115, párr. 37.

⁴⁵ *Ibid.*, párrs. 37 y 38.

⁴⁶ *Ibid.*, párr. 40.

⁴⁷ A/CN.9/WG.IV/WP.116, sección 3.

identificación único en el momento de la creación de un documento transmisible electrónico. El número de identificación único no proporciona de por sí seguridad de singularidad, pero el sistema garantiza que cada número de identificación único tenga por contrapartida un solo documento correspondiente. Este es el enfoque seguido en la ERMCA del Japón⁴⁸, en la legislación de la República de Corea sobre conocimientos de embarque electrónicos⁴⁹, y en la legislación de los Estados Unidos de América relativa a los resguardos de almacén electrónicos⁵⁰.

46. En el Código de Comercio Uniforme se adopta un enfoque neutral con respecto al sistema seguido, pues sus disposiciones tratan de la singularidad en el contexto de los requisitos para establecer el control, respectivamente, sobre los documentos de titularidad electrónicos⁵¹ y los valores inmobiliarios electrónicos⁵². Las salvaguardias mediante las cuales se procura garantizar la singularidad en este

⁴⁸ Artículo 16 1) vii) de la ERMCA.

⁴⁹ A/CN.9/692, párr. 31.

⁵⁰ Códigos de Reglamentos Federales, Título 7: Agricultura, Parte 735-Reglamento de la Ley sobre Almacenes de los Estados Unidos, Subtítulo D resguardos de almacén, artículo 735.303 b) 5).

⁵¹ Artículo 7-106 del Código de Comercio Uniforme, Control del documento de titularidad electrónico.

- a) Una persona tiene control sobre un documento de titularidad electrónico si el sistema empleado para demostrar la transmisión de intereses en el documento electrónico establece de manera fehaciente que la persona es la persona a la que se emitió o transfirió el documento electrónico.
- b) Un sistema habrá de satisfacer el inciso a), y se considerará que una persona tiene control de un documento de titularidad electrónico si el documento ha sido creado, archivado y asignado de manera tal que:

- 1) exista un solo ejemplar fehaciente del documento que es único, identificable y, salvo lo dispuesto en los párrafos 4), 5) y 6), inalterable;
- 2) el ejemplar fehaciente identifique a la persona que afirma tener control como:
 - A) la persona a la que se emitió el documento; o
 - B) si el ejemplar fehaciente indica que el documento ha sido transferido, la persona a la cual se haya efectuado la transmisión más reciente del documento;
- 3) el ejemplar fehaciente se comunique y sea mantenido por la persona que afirma ejercer control o su custodio designado;
- 4) solo puedan hacerse copias o enmiendas que agreguen o modifiquen al cesionario identificado del ejemplar fehaciente con el consentimiento de la persona que afirma ejercer el control;
- 5) cada copia del ejemplar fehaciente y cualquier copia de otra copia sea fácilmente identificable como copia que no es el ejemplar fehaciente; y
- 6) toda enmienda del ejemplar fehaciente sea fácilmente identificable como fehaciente o no fehaciente.

⁵² Artículo 9-105 del Código de Comercio Uniforme. Control del valor mobiliario electrónico.

Una parte garantizada ejerce control sobre un valor mobiliario electrónico si el documento o documentos que contiene o contienen el valor mobiliario ha sido o han sido creados, archivados y asignados de manera tal que:

- 1) exista un solo ejemplar fehaciente del documento o documentos que sea único, identificable y, salvo lo dispuesto en contrario por los párrafos 4), 5) y 6), inalterable;
- 2) el ejemplar fehaciente identifique a la parte garantizada como al cesionario del documento o documentos;
- 3) el ejemplar fehaciente sea comunicado y esté mantenido por la parte garantizada o su custodio designado;
- 4) las copias o revisiones que agreguen o modifiquen a un determinado cesionario del ejemplar fehaciente puedan efectuarse solamente con la participación de la parte garantizada;
- 5) cada copia del ejemplar fehaciente y cualquier copia de otra copia sean fácilmente identificables como copias que no son el ejemplar fehaciente; y
- 6) cualquier modificación del ejemplar fehaciente sea fácilmente identificable como una revisión fehaciente o no fehaciente.

enfoque consisten en la capacidad del sistema de crear un solo ejemplar fehaciente que sea único e identificable, la facultad de la persona que ejerce control sobre el único ejemplar fehaciente del documento transmisible electrónico para controlar la emisión de cualquier copia no autorizada de aquel, y la facilidad de identificar como tal cualquier copia del único ejemplar fehaciente del documento transmisible electrónico y de cualquier enmienda que se le haya introducido.

47. En la legislación de la República de Corea relativa a las letras de cambio electrónicas parece haberse adoptado un enfoque híbrido. En efecto, el artículo 8 del Decreto Presidencial sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos⁵³ trata de la equivalencia funcional del pagaré electrónico. En particular, el párrafo 2 de ese artículo indica que el pagaré electrónico irá acompañado de un mecanismo que no permita la creación de duplicados. El sistema de pagarés electrónicos de la República de Corea es gestionado mediante un registro (“UNote”)⁵⁴. Sin embargo, ese sistema de registro interactúa con los usuarios a través de una red bancaria electrónica, debido a que los pagarés electrónicos son emitidos, endosados y pagados por conducto de esa red. Por consiguiente, el sistema de registro puede beneficiarse de la confianza adicional generada por el hecho de que los clientes bancarios electrónicos estén sujetos a estrictos procedimientos de identificación y se valgan de métodos de autenticación y autorización que confieren un nivel más alto de seguridad. Este nivel más alto de seguridad en cuanto a la identidad de los usuarios puede tener un efecto positivo en los riesgos asociados con la noción de singularidad del documento transmisible electrónico.

48. Existen otros métodos para garantizar la singularidad. Uno de ellos es el adoptado por la Ley de compensación de cheques para el siglo XXI (“Ley de cheques XXI”) de los Estados Unidos de América. La Ley de cheques XXI facilita la compensación bancaria electrónica (truncamiento) de cheques, es decir, la supresión del cheque de papel en favor de una copia electrónica durante el proceso de cobranza del cheque. En términos más precisos, permite la creación de un título negociable, denominado “cheque sustituto”, que reemplaza al cheque de papel. El cheque sustituto también se basa, en realidad, en papel, puesto que se trata de la versión impresa de la imagen electrónica del cheque original de papel. La Ley de cheques XXI declara que el cheque sustituto equivale al cheque original para todos los fines.

49. La Ley de cheques XXI aborda el problema de la singularidad exigiendo al banco que transfiere, presenta o devuelve un cheque sustituto y recibe una contraprestación por ese cheque, que garantice a otras partes interesadas que no se les presentará para el cobro o se les devolverá el cheque sustituto ni el cheque original, en forma alguna y, por tanto, que no se les pedirá que efectúen el mismo pago dos veces (artículo 5). Por consiguiente, el mecanismo para garantizar la singularidad se basa en una asignación de riesgo y no en una norma jurídica que asegure la singularidad del documento. Además, la ley procura asegurar la singularidad de la ejecución por parte del deudor más que la singularidad del documento mismo que da derecho a esa ejecución.

50. Puede encontrarse un enfoque alternativo de la compensación bancaria electrónica de cheques en el Sistema de compensación y archivo de cheques en

⁵³ Decreto Presidencial núm. 18637, de 31 de diciembre de 2004, y enmiendas subsiguientes.

⁵⁴ Se encontrará más información en www.unote.or.kr.

imagen (ICAS) elaborado recientemente por el Banco de Tailandia. Si bien los fines y mecanismos de ICAS son, en general, similares a los de la Ley de cheques XXI, ICAS se está llevando a la práctica sin la promulgación de leyes especiales, basándose exclusivamente en la Ley sobre transacciones electrónicas de Tailandia, que representa la incorporación en la legislación nacional de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico⁵⁵.

2. Control del documento transmisible electrónico

51. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos que se ocupan de los documentos transmisibles electrónicos, el concepto de “control” sobre un documento electrónico se considera el equivalente funcional de la posesión. Es decir que la persona que ejerce el control sobre el documento transmisible electrónico es considerada como el tenedor capaz de hacer valer ese documento. Cuando el control de un documento transmisible electrónico se utiliza como equivalente de la posesión del documento de papel transferible, el traspaso del control sobre el documento transmisible electrónico hace las veces de entrega, del mismo modo en que la transmisión de la posesión (y el endoso si procede) se produce con la entrega del documento de papel transferible.

52. En otras palabras, se entiende por “control” la capacidad de transmitir el documento transmisible electrónico y de ejercitar el derecho que acredita ese documento. En tanto que los derechos contenidos en un documento transmisible electrónico se rigen por el derecho sustantivo aplicable a ese documento transmisible electrónico, en el análisis que se realiza a continuación se centrará la atención en el concepto de “control” como equivalente de la posesión de un documento de papel.

53. Las leyes existentes que permiten el uso de documentos transmisibles electrónicos mediante el control sobre el documento pueden dividirse en tres grupos. Las leyes del primer grupo están redactadas de manera que dan cabida tanto a los documentos consignados en papel como a los electrónicos. Las del segundo grupo proporcionan normas genéricas para reconocer la equivalencia funcional entre los documentos de papel y los electrónicos. Las del tercer grupo adoptan el concepto de control ejercido en un sistema de registro. Por consiguiente, mientras que las leyes de los dos primeros grupos son neutrales en cuanto al sistema, el tercero no lo es.

54. Las Reglas de Rotterdam ofrecen un ejemplo del primer grupo de leyes en que la definición del documento de titularidad contenida en el derecho sustantivo (es decir, las propias Reglas de Rotterdam) ya prevé la neutralidad con respecto a los medios. El artículo 1 (párrafos 21 y 22) de las Reglas de Rotterdam indica que el concepto de control se encuentra estrechamente vinculado tanto a la emisión como a la transmisión del documento electrónico de transporte negociable⁵⁶. El párrafo 1

⁵⁵ Banco de Tailandia, Imaged Cheque Clearing and Archive System, sub. 9, disponible en www.bot.or.th/English/PaymentSystems/PSServices/ChequeClearingSys/ICAS/Pages/ImagedCheque.aspx.

⁵⁶ Artículo 1, párrafo 21. Por “emisión” de un documento electrónico de transporte negociable se entenderá su emisión por medio de procedimientos que aseguren que el documento es susceptible de permanecer bajo control exclusivo desde su creación hasta que pierda su validez o eficacia. Artículo 1, párrafo 22. Por “transmisión” de un documento electrónico de transporte negociable se entenderá el traspaso del control exclusivo sobre el documento.

del artículo 9 de las Reglas de Rotterdam enuncia además una norma general para establecer la equivalencia funcional entre la posesión de un documento de papel y el control sobre un documento electrónico⁵⁷.

55. El artículo 7-106 (Control del documento de titularidad electrónico) del Código de Comercio Uniforme es un ejemplo del segundo grupo de leyes⁵⁸. En esa disposición se establece la equivalencia funcional entre el control en un entorno de papel (ejercido normalmente mediante la posesión efectiva o presumible del documento de papel) y el control en el entorno electrónico mediante el uso de un sistema que establezca de manera fehaciente la entidad a la cual se emitió o transfirió el documento transmisible electrónico (es decir, el tenedor). Para ello, el sistema debe prever la existencia de un solo ejemplar fehaciente, que constituye el equivalente funcional del concepto de singularidad. Además, el sistema debe identificar de manera fehaciente al primer tenedor del documento transmisible electrónico o al cesionario.

56. Puesto que el artículo 7-106 b) 3) del Código de Comercio Uniforme permite que el ejemplar fehaciente sea comunicado y mantenido por la persona que ejerce control o su custodio designado, la disposición es compatible con el sistema de registro, donde el custodio designado vendría a ser el administrador del registro, así como con el sistema de símbolo, en que la persona que afirma ejercer control podría comunicar y mantener el ejemplar fehaciente en su poder o confiarlo a un tercero en depósito. Como ya se señaló *supra* (véase el párrafo 46), el artículo 7-106 b) 4) a 6) del Código de Comercio Uniforme menciona ciertas condiciones para alcanzar y mantener la singularidad de los documentos transmisibles electrónicos.

57. Los detalles de la aplicación del sistema previsto *supra* se han examinado en la literatura con respecto al artículo 9-105 del Código Uniforme de Comercio, que contiene una disposición similar aplicable a los valores mobiliarios electrónicos⁵⁹. Es importante subrayar que la determinación de la existencia de hecho de esos elementos que establecen el control no debe pretender llegar a la perfección absoluta; en efecto, se trata más bien de lograr un grado suficiente de certeza. En una determinación de ese tipo debería examinarse la intersección del derecho y la tecnología a fin de determinar si el sistema utilizado, en sus componentes humano y tecnológico y en los procesos conexos, ofrece un grado suficiente de fiabilidad.

58. Quizá puedan obtenerse parámetros más detallados para la evaluación de la fiabilidad de un sistema para la gestión de los documentos transmisibles electrónicos a partir del examen de todas las disposiciones aplicables. En otras palabras, las normas tales como las contenidas en el artículo 7-106 del Código de Comercio Uniforme tienen que complementarse y especificarse mediante

⁵⁷ Artículo 9, párrafo 1. El empleo de un documento electrónico de transporte negociable deberá observar ciertos procedimientos que prevean:

- a) El método para la emisión y la transmisión del documento al tenedor previsto;
- b) Las medidas para asegurar que el documento electrónico de transporte negociable emitido conserve su integridad;
- c) La forma en que el tenedor podrá probar su condición de tal; y
- d) [...].

⁵⁸ *Supra*, nota 51.

⁵⁹ Working Group on Transferability of Financial Assets, Framework for Control over Electronic Chattel Paper – Compliance with UCC § 9-105, 61 *The Business Lawyer* (2006), 2.

estipulaciones contractuales, así como con normas establecidas voluntariamente por la industria, herramientas de reglamentación conjunta, etc.

59. Las leyes del tercer grupo se basan en el empleo de registros electrónicos. En los sistemas cerrados, como esos registros electrónicos, la legislación supone que la singularidad del documento y la identificación adecuada de la parte interesada pueden bastar para dar derecho al tenedor a transmitir el documento transmisible electrónico. Es posible que no se aborde expresamente el concepto de control como tal, pero está implícito en los mecanismos establecidos para el funcionamiento del registro. Por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 9 de la ERMCA del Japón dispone que se presumirá que la persona registrada electrónicamente⁶⁰ es el titular legítimo del crédito monetario registrado electrónicamente relacionado con el documento electrónico en cuestión.

60. En la legislación de la República de Corea sobre los conocimientos de embarque y los pagarés electrónicos se ha adoptado un enfoque similar⁶¹. En particular, el párrafo 3 del artículo 6 de la Ley sobre Emisión y Negociación de Letras de Cambio y Pagarés Electrónicos indica que cuando el emisor firma el pagaré electrónico con un certificado digital, dicho pagaré se considerará debidamente sellado o firmado de conformidad con el artículo 75, párrafo 7, de esa Ley. La disposición, que parece ser tecnológicamente específica con respecto a las firmas electrónicas, establece el control basándose en la identificación y la garantía de singularidad equivalente a la proporcionada por un registro electrónico.

61. Pueden contemplarse disposiciones específicas para el caso de tenedores múltiples, de manera que el control pueda ejercerse conjunta o separadamente, según el derecho sustantivo aplicable. La existencia de deudores múltiples, responsables solidarios, parece presentar menos problemas en la medida en que dichos deudores no necesiten ejercer control. Sin embargo, puesto que pueden intervenir en la circulación de un documento transmisible electrónico (por ejemplo, como destinatarios de notificaciones), puede resultar útil la adopción de disposiciones especiales.

3. Identificación del emisor y del primer tenedor

62. Para que la creación del documento transmisible electrónico sea eficaz, es necesaria la identificación del emisor y del primer tenedor del documento. De hecho, el equivalente funcional de la posesión debería determinar la identidad del único tenedor con derecho a la ejecución y debería excluirse a todas las personas que no fueran el tenedor del derecho a exigir la ejecución⁶². El sistema debería poder identificar al deudor con el mismo grado de fiabilidad, si dicha identificación es necesaria con arreglo al derecho aplicable.

63. La fiabilidad de los mecanismos para la identificación, autenticación y autorización del tenedor del documento (lo que suele denominarse “nivel de garantía” o “grado de certeza”) es de importancia fundamental para asegurar la aceptación de los documentos transmisibles electrónicos en la práctica comercial.

⁶⁰ La expresión “persona registrada electrónicamente”, usada en la ERMCA, significa la persona que figura en la constancia de los créditos monetarios registrados como tenedor de la obligación u obligante de los créditos monetarios registrados electrónicamente.

⁶¹ A/CN.9/692, párr. 32.

⁶² A/CN.9/737, párr. 66.

Sin embargo, parece pertinente también observar que, de manera semejante a lo que ocurre en el entorno de los documentos de papel, la confianza entre las partes en una operación electrónica se basa en varios factores, incluidos algunos relacionados con la propia operación, tales como el valor, y otros relacionados con los vínculos existentes entre las partes, incluidos los intercambios ocurridos en el pasado y la interacción directa. Estas consideraciones se aplican a todas las fases del ciclo vital del documento transmisible electrónico.

64. En el entorno de papel, el emisor crea el documento e identifica en ese documento al primer tenedor, a menos que presuma que el documento habrá de circular de manera anónima (“al portador”). En el entorno electrónico, estas operaciones pueden no duplicarse necesariamente en exactamente los mismos términos debido a los requisitos técnicos. Por ejemplo, si el sistema se basa en los servicios prestados por un tercero, como en el caso del administrador de un registro, ese tercero comunicará el documento transmisible electrónico en nombre del emisor⁶³. Además, el anonimato puede no estar permitido o no ser posible en un entorno electrónico y, por tanto, esos documentos transmisibles electrónicos no podrán ser emitidos al portador⁶⁴.

65. De este modo, en la legislación sobre conocimientos de embarque electrónicos de la República de Corea, que ha optado por un sistema de registro, el porteador presenta una solicitud al administrador del registro para que emita el conocimiento de embarque electrónico⁶⁵. Sin embargo, en el párrafo 1 del artículo 5 de la ERMCA del Japón se dispone que la solicitud sea formulada tanto por el titular del derecho registrado electrónicamente como por el deudor de la operación registrada electrónicamente. Este último criterio permite asegurarse de que todas las partes estén de acuerdo en el uso de medios electrónicos.

66. La identificación, autenticación y autorización fiables de las partes que participan en la creación de un documento transmisible electrónico, así como en las fases subsiguientes de su ciclo vital, son de importancia crítica para inspirar confianza en el sistema. Esto se trata en la actualidad, en parte por lo menos, en la ley sobre firmas electrónicas. En esa ley se prevé la posibilidad de dejar a criterio de las partes la determinación del grado adecuado de autenticación, o la enumeración de los requisitos para la autenticación⁶⁶. La Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas, de 2001, puede proporcionar orientación inicial en la materia.

67. Cabe observar que los sistemas de registro normalmente presuponen una estricta identificación no electrónica de los usuarios admitidos en esos sistemas. Por otro lado, los sistemas de símbolo pueden no requerir o prever la identificación previa de las partes y exigir una identificación fiable solo en el momento de la operación en que interviene un documento transmisible electrónico. La futura evolución en la esfera de la gestión de la identidad podría resultar particularmente pertinente a este respecto.

68. La legislación existente sobre los documentos transmisibles electrónicos se refiere a las disposiciones generales sobre firmas electrónicas pero no establece

⁶³ *Ibid.*, párr. 59.

⁶⁴ *Ibid.*, párr. 34.

⁶⁵ A/CN.9/692, párr. 30.

⁶⁶ A/CN.9/737, párr. 69.

normas específicas⁶⁷. En ciertos casos, podría resultar posible aprovechar los elementos de autenticación adicionales disponibles en otros sistemas de tecnología de la información. Por ejemplo, la legislación de la República de Corea sobre los pagarés electrónicos se apoya en la función de los bancos como intermediarios para la identificación de las cuentas bancarias de las partes que intervienen en la emisión y transmisión de los pagarés electrónicos. El sistema Bolero también permite a los usuarios incorporarse como miembros por conducto de sus bancos⁶⁸. En estos casos, la posibilidad de utilizar factores de identificación extrínsecos a los documentos transmisibles electrónicos puede aumentar apreciablemente el nivel de garantía.

69. En la práctica actual, especialmente en el caso de operaciones de gran valor, ya sea por mandato legislativo u opción contractual, el uso de las tecnologías basadas en la infraestructura de clave pública (ICP) parece ser el más difundido. Sin embargo, si la legislación sobre firmas electrónicas prescribe el uso de tecnologías específicas, pueden plantearse dificultades para el reconocimiento transfronterizo de esas firmas electrónicas. Estas dificultades pueden soslayarse mediante la adopción de disposiciones adecuadas, similares a la del artículo 12 de la Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas y el artículo 9, párrafo 3 de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas.

70. Debe prestarse especial atención a la arquitectura del sistema elegido. En realidad, en ciertos enfoques, puede pedirse a los usuarios que soliciten su inscripción al administrador del sistema para poder tener acceso al sistema. En tal caso, quizá debiera considerarse la conveniencia de proporcionar orientación sobre las normas de identificación de las partes por el administrador del sistema.

⁶⁷ Véase, por ejemplo, la legislación sobre los conocimientos de embarque electrónicos de la República de Corea sobre la elección de un sistema basado en la infraestructura de clave pública (ICP) para las firmas electrónicas (A/CN.9/692, párr. 28).

⁶⁸ www.bolero.net/en/home/enrolment.aspx.

(A/CN.9/WG.IV/WP.118 y Add.1) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre cuestiones jurídicas relativas a la utilización de documentos transmisibles electrónicos, presentada al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 46º período de sesiones**ADICIÓN****Índice**

	<i>Párrafos</i>
III. Cuestiones jurídicas relativas a los documentos transmisibles electrónicos (<i>continuación</i>)	1-54
B. Circulación de los documentos transmisibles electrónicos	1-29
1. Enmienda de un documento transmisible electrónico	2-5
2. Traspaso del control	6-18
3. Correcciones	19-21
4. Garantías y prendas	22-25
5. Fraccionamiento y consolidación de los documentos transmisibles electrónicos	26-28
6. Participación del emisor durante el ciclo vital	29
C. Fin del ciclo vital de los documentos transmisibles electrónicos	30-54
1. Presentación para la ejecución	30-41
2. Conversión o reemplazo	42-49
3. Cancelación	50-54
IV. Otras cuestiones relacionadas con los documentos transmisibles electrónicos	55-73
A. El administrador del registro de documentos transmisibles electrónicos como tercero	55-60
B. Reconocimiento transfronterizo de los documentos transmisibles electrónicos	61-73

III. Cuestiones jurídicas relativas a los documentos transmisibles electrónicos (*continuación*)**B. Circulación de los documentos transmisibles electrónicos**

1. Puede resultar necesario enmendar un documento transmisible electrónico a fin de reflejar ciertos actos jurídicos que lo afectan. La razón más común es la transmisión. Otras razones posibles incluyen la subrogación, la sucesión (herencia o fusión), la garantía, el fraccionamiento o combinación del documento. En los sistemas de registro, la enmienda puede no afectar al propio documento electrónico sino más bien a sus atributos consignados en el registro.

1. Enmienda de un documento transmisible electrónico

2. En general la enmienda de un documento transmisible electrónico requiere el consentimiento de la entidad que ejerce control. Según el tipo de enmienda y del tipo de operación que haya de constar en la enmienda, puede hacer falta el consentimiento de otras partes. Así, por ejemplo, la transmisión de un documento transmisible electrónico puede exigir el consentimiento del cesionario para quedar perfeccionada. Esos requisitos son comunes cuando se trata de documentos de papel y es probable, por tanto, que se encuentren normas pertinentes en el derecho sustantivo.

3. Son escasas las normas generales sobre la enmienda de documentos electrónicos en las leyes existentes. Esto podría deberse al hecho de que se considere que los documentos electrónicos son producto de acuerdos contractuales y, por tanto, las enmiendas pueden ser convenidas por las partes en el contrato en cualquier momento, siempre que se respeten los principios básicos del uso de las comunicaciones electrónicas.

4. El artículo 26 de la ERMCA dispone que la modificación (es decir, la enmienda) del contenido de los créditos monetarios registrados electrónicamente no será efectiva si no se crea un documento de la modificación, y el artículo 27 prescribe el contenido de los documentos de modificación. Además, el artículo 29 1) dispone que todas las personas que tengan interés en documentos electrónicos pueden solicitar documentos de modificación.

5. Puede resultar necesaria la cooperación de un tercero para enmendar el documento transmisible electrónico si el sistema, por ejemplo un registro electrónico, presupone la existencia de tal tercero¹.

2. Traspaso del control

6. La transmisión del derecho al cumplimiento de una obligación prescrita en un documento de papel se produce cuando se transfiere la posesión efectiva o presumible del documento. En un entorno electrónico, esa transmisión se produce con el traspaso del control sobre el documento transmisible electrónico. Este traspaso del control debe tener en cuenta dos elementos: el perfeccionamiento de la transmisión entre el cedente y el cesionario, y el perfeccionamiento de la transmisión frente a todas las demás partes, que se consideran terceros con respecto a esa transmisión.

7. Puede surgir una complicación adicional por la intervención necesaria, en ciertas tecnologías, de un tipo especial de tercero, encargado de asistir con los aspectos técnicos de la transmisión, como, por ejemplo, el administrador de un registro electrónico. Este tiene obligaciones especiales con el cedente y el cesionario en virtud de los servicios que se ha comprometido a prestar.

8. En el sistema neutral con respecto a los medios técnicos de las Reglas de Rotterdam, en el párrafo 2 del artículo 57 se dispone que cuando se haya emitido un documento electrónico de transporte negociable, su tenedor podrá transmitir los derechos incorporados en el documento, tanto si se ha emitido simplemente a la

¹ Véase, por ejemplo, el mecanismo adoptado por la legislación de la República de Corea sobre los conocimientos de embarque (A/CN.9/692, párrs. 35 y 36).

orden como si se ha emitido a la orden de una persona determinada, mediante la transmisión del documento por los procedimientos indicados en el párrafo 1 del artículo 9 (procedimientos para el empleo de los documentos electrónicos de transporte transmisibles y negociables). Un elemento interesante de esa disposición es que ofrece la posibilidad de que la transmisión se efectúe por endoso en blanco y no por endoso a una persona determinada (artículo 57, párrafo 1). En un entorno electrónico esto exigiría que el sistema fuera capaz de dar cabida a documentos transmisibles electrónicos sin un tenedor designado².

9. El artículo 7-501 b) del Código de Comercio Uniforme trata específicamente de la transmisión de documentos transmisibles electrónicos³. Se enuncia en él el principio de que el traspaso del control, según se desprende de la existencia de un solo ejemplar fehaciente del documento transmisible electrónico, es equivalente a la entrega y, en caso necesario, el endoso del documento de titularidad de papel. Esta disposición parece reafirmar la eficacia de los principios del derecho sustantivo aplicables a los documentos de titularidad en un entorno electrónico.

10. El artículo 7-501 b) también parece permitir la existencia de un equivalente electrónico de los documentos de titularidad al portador, puesto que el comentario oficial sobre esta disposición indica que la negociación puede efectuarse, con arreglo a ese artículo, por cualquier tenedor independientemente de la forma en que este haya adquirido la posesión o el control del documento⁴. Sin embargo, la posibilidad de aplicar esta norma puede exigir una consideración sumamente cuidadosa de los requisitos necesarios para la autenticación de las partes.

11. A ese respecto, los párrafos 4 a 6 del artículo 7-106 b) del Código de Comercio Uniforme requieren, en consonancia con las normas generales, que la enmienda del documento transmisible electrónico, incluida para los fines del traspaso del control, sea fácilmente identificable como autorizada⁵. Esto es especialmente necesario para la protección de terceros. La satisfacción de este requisito, si bien preserva el anonimato total del tenedor, puede dar lugar a una impugnación técnica.

² A/CN.9/WG.IV/WP.118, párr. 64.

³ Artículo 7-501 b) “Se aplican las siguientes normas a un documento electrónico de titularidad negociable:

1) Si en las condiciones originales el documento se ha extendido a la orden de una persona determinada o al portador, el documento se negocia mediante la entrega del documento a otra persona. No es necesario el endoso de esa persona determinada para negociar el documento.

2) Si en las condiciones originales el documento se ha extendido a la orden de una persona determinada y esa persona tiene control sobre el documento, el efecto es el mismo que si el documento hubiera sido negociado.

3) Un documento es debidamente negociado si se negocia de la manera especificada en el apartado de este artículo con un tenedor que lo adquiere de buena fe, sin notificación de ninguna excepción o reclamación que pueda oponerle cualquier persona, y a título oneroso, a menos que se determine que la negociación no se ha hecho en el curso ordinario de las actividades comerciales o financieras o supone la aceptación de entrega del documento en cumplimiento o pago de una obligación monetaria.”

⁴ National Conference of Commissioners on Uniform State Laws — The American Law Institute, Revision of Uniform Commercial Code Article 7 — Documents of Title, with Prefatory Notes and Official Comments, 2004, pág. 63.

⁵ A/CN.9/WP.IV/WP.118, nota de pie de página 51.

12. En los sistemas de registro, el traspaso del control se produce con la sustitución de la persona facultada para ejercer ese derecho de conformidad con las constancias del registro. El artículo 17 de la ERMCA especifica que la cesión de un crédito monetario registrado electrónicamente no será efectiva hasta que se haga constar la cesión en un documento. En el artículo 18 se establece el contenido del documento de cesión⁶.

13. La legislación de la República de Corea sobre conocimientos de embarque electrónicos especifica que el endoso de un conocimiento de embarque electrónico se produce con la transmisión de un mensaje del tenedor del conocimiento de embarque al administrador del registro que contenga la orden de traspasar el control sobre el conocimiento de embarque a un cesionario determinado y la identificación del conocimiento de embarque mediante su número de identificación único. El cesionario empieza a ejercer control sobre el conocimiento de embarque al recibir el mensaje en el que se le informa acerca de la transmisión⁷.

14. Algunas leyes pueden fijar un máximo para el número de transmisiones posibles. Así, por ejemplo, el artículo 7 5) de la Ley de la República de Corea sobre la Emisión y Negociación de Letras de Cambio y Pagarés Electrónicos establece un máximo de 20 endosos para cada pagaré electrónico. En los sistemas de registro, este máximo puede estar determinado también en virtud de un acuerdo contractual o por decisión del administrador del registro; en tal caso, el máximo debe constar en el documento transmisible electrónico para tener validez y fuerza ejecutoria. En este orden de ideas, el artículo 16 2) de la ERMCA dispone que en la constancia del ejercicio de los derechos se pueden consignar los acuerdos para limitar el número de veces que puede hacerse un documento de cesión.

15. Hay otro aspecto que se relaciona con la posibilidad de que el cesionario rechace la transmisión después de examinar el documento transmisible electrónico o de otro procedimiento adecuado. Esta posibilidad parece haberse previsto en el artículo 11 2) del Decreto Presidencial de la República de Corea sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos. Según ese artículo, la parte que rechaza la transmisión deberá cumplimentar un formulario especial e informar al administrador del registro acerca de su rechazo. El administrador del registro adjuntará entonces un certificado de rechazo a la constancia del pagaré electrónico, y el efecto jurídico de ello será que el destinatario original no recibirá el pagaré electrónico.

16. La identificación fehaciente del tenedor del documento transmisible electrónico es importante no solo para permitir el ejercicio del control sino también para verificar la validez de la cadena de transmisiones del documento transmisible electrónico⁸. Es posible que hagan falta datos fidedignos y completos sobre las enmiendas introducidas en un documento transmisible electrónico para otros fines.

17. En general, y a falta de estipulaciones contractuales en contrario, el momento de la transmisión debería determinarse con arreglo a las normas generales aplicables

⁶ El artículo 26 de la ERMCA dispone, como norma general, que la “manifestación de intención” de modificar el contenido de un crédito monetario registrado electrónicamente no tendrá efecto hasta que se modifique ese crédito, salvo disposición en contrario de la ERMCA. La cesión del derecho es uno de los casos comprendidos por la expresión “salvo disposición en contrario de la presente Ley”.

⁷ A/CN.9/692, párrs. 33 y 34.

⁸ A/CN.9/737, párr. 68.

al envío y recibo de comunicaciones electrónicas, según se desprenden del artículo 10 de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas. Cabría considerar que las comunicaciones intercambiadas en el contexto de un registro electrónico “no salen del sistema bajo el control de la parte que ha enviado la comunicación electrónica en nombre del autor original” para los fines de la aplicación de estas normas.

18. Por último, la entidad que ejerce el control puede no desear que el documento transmisible electrónico siga circulando. En el sistema de registro, esto exigiría la presentación de una solicitud al administrador del registro⁹.

3. Correcciones

19. El artículo 10 de la ERMCA enumera los casos que justifican la introducción de correcciones en un documento electrónico. Se usan para rectificar, entre otros, errores de ingreso (es decir, la información proporcionada por la parte que solicita el documento es diferente de la que se ha hecho constar en el documento), emisión de documentos electrónicos sin mediar solicitud, omisión de detalles de los que ha de dejarse constancia y la cancelación prematura del documento electrónico.

20. Con arreglo a ese artículo, si un tercero tiene interés en que se corrija el documento electrónico, la corrección podrá hacerse solo con el consentimiento de ese tercero. Además, el administrador del registro está obligado a notificar tanto a la entidad que ejerce el control sobre el documento electrónico corregido como a la parte obligada (es decir, el deudor) del derecho electrónicamente registrado acerca de la corrección, una vez efectuada.

21. En otros casos, a falta de disposiciones legislativas, en las estipulaciones contractuales se enunciarán normas detalladas sobre la corrección de los documentos transmisibles electrónicos. Así sucede, por ejemplo, con los Mortgage Electronic Registration Systems (MERS) en los Estados Unidos de América¹⁰.

4. Garantías y prendas

22. El tratamiento de las garantías y prendas respecto de los documentos transmisibles electrónicos suele examinarse en la legislación relativa al equivalente electrónico de los títulos transmisibles.

23. El artículo 6 de la ERMCA prevé el tratamiento jurídico de las garantías registradas electrónicamente. El artículo 32 de la ERMCA enuncia la información que ha de hacerse constar en el documento de la garantía electrónica: declaración de la intención de proporcionar la garantía; nombre y domicilio del garante; información necesaria para identificar la obligación principal; y la fecha. Puede

⁹ Con respecto a los pagarés electrónicos en la República de Corea, véase el artículo 14 del UNote Registry Service Agreement, documento de índole contractual.

¹⁰ Los MERS cumplen varias funciones útiles en el sector hipotecario. Por ejemplo, permiten a prestamistas e inversionistas transmitir hipotecas sin dejar constancia de las cesiones en los registros públicos locales, ahorrándoles el pago de derechos de registro. Y permiten a los consumidores, las empresas de títulos de propiedad y los profesionales del sector de bienes raíces identificar fácilmente a los tenedores actuales de las hipotecas registradas y obtener exoneraciones pese a cualesquiera transmisiones de las hipotecas o fusiones o adquisiciones de los prestamistas e inversionistas interesados que, de otro modo, podrían dificultar la determinación de la propiedad.

agregarse información para dejar constancia de acuerdos contractuales. El artículo 35 1) de la ERMCA, en el que se indica que el garante que efectúa un pago contra la obligación principal adquiere un crédito monetario electrónicamente registrado por la suma equivalente, constituye una aplicación del principio general de la subrogación del garante en un entorno electrónico.

24. El artículo 7 de la ERMCA trata de las prendas de créditos monetarios registrados electrónicamente. Según el artículo 36 1) de la ERMCA, la creación de una prenda con respecto al crédito monetario registrado electrónicamente no tiene eficacia hasta que se haga el documento electrónico conexo. De este modo, el perfeccionamiento del documento donde se indica la existencia de la prenda es el equivalente de la desposesión en el mundo físico. En el artículo 40 también se prevén explícitamente las subprendas. En el artículo 37 1) de la ERMCA se enumeran los elementos que deben indicarse en la constancia de la prenda: declaración de intención de crear la prenda; nombre y domicilio del acreedor prendario; información necesaria para identificar el crédito garantizado; identificador único de la prenda; fecha.

25. El artículo 8 de la Ley sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos, de la República de Corea, permite el otorgamiento de una garantía respecto de un pagaré electrónico. En el artículo 20 1) del Acuerdo de Prestación de Servicios pertinente se enumeran los elementos que deben figurar en la constancia de la garantía, entre otros: identificación del pagaré electrónico garantizado; suma de la garantía; el propio término “garantía”; y la identificación de las partes pertinentes mediante sus cuentas bancarias designadas.

5. Fraccionamiento y consolidación de los documentos transmisibles electrónicos

26. El fraccionamiento y la consolidación de los documentos transmisibles electrónicos puede resultar necesaria, por ejemplo, en relación con la circulación de los equivalentes electrónicos de los conocimientos de embarque. Pueden darse operaciones similares cuando se combinan títulos negociables en el contexto de su transmisión o titularización.

27. El artículo 8 de la ERMCA proporciona normas para la división de los créditos monetarios registrados electrónicamente, incluidos los casos de separación con respecto a deudores o acreedores múltiples. De acuerdo con el artículo 43 3) de la ERMCA, solo el acreedor puede solicitar la división de un documento electrónico. El artículo 44, al enumerar los datos que deben ingresarse en el documento sobre la división, especifica que deben indicarse los identificadores únicos tanto del documento del crédito monetario electrónico original como del documento del crédito monetario electrónico resultante después de la división.

28. En la República de Corea, solo la persona que ejerce control sobre el conocimiento de embarque electrónico puede presentar una solicitud al administrador del registro para que fraccione o consolide el conocimiento de embarque. Sin embargo, también hace falta el consentimiento del porteador si, como resultado del fraccionamiento o de la consolidación, queda cancelado el conocimiento de embarque electrónico¹¹.

¹¹ Artículo 19 del Acuerdo de Prestación de Servicios del e-Bill of Lading Korea Portal.

6. Participación del emisor durante el ciclo vital

29. La cuestión de la medida en que el emisor ha de seguir participando en la transmisión de los documentos transmisibles electrónicos se aborda en el derecho sustantivo pertinente. Si bien el documento transmisible electrónico, una vez emitido, debería poder circular sin participación del emisor¹², puede haber casos en que el emisor deba seguir participando, por ejemplo, cuando el documento transmisible electrónico se convierte en un documento de papel. La participación del emisor durante el ciclo vital del documento transmisible electrónico dependerá también del tipo de tecnología utilizado.

C. Fin del ciclo vital de los documentos transmisibles electrónicos

1. Presentación para la ejecución

30. La presentación de un documento de papel puede exigir una verificación de la cadena de endosos a fin de asegurarse de que se confiera el derecho de ejecución a la entidad a la que corresponde en virtud de la circulación del documento. En un entorno electrónico, la cadena de transmisiones queda documentada en el ejemplar fehaciente del documento transmisible electrónico o en los atributos de ese documento archivado en un registro. Sin embargo, el deudor puede verse obligado a seguir normas específicas para verificar la validez y fuerza ejecutoria del documento transmisible electrónico presentado¹³.

31. En el artículo 47 1) a) ii) de las Reglas de Rotterdam, se hace referencia a la necesidad de que el tenedor demuestre que se han seguido los procedimientos para establecer el control. El porteador puede negarse a efectuar la entrega si esos procedimientos no se han seguido.

32. El artículo 7-501 b) 1) del Código de Comercio Uniforme sobre documentos de titularidad electrónicos negociables dice que si los términos originales del documento indican que se ha extendido a la orden de una persona determinada o al portador, el documento se negocia mediante la entrega del documento a otra persona. Se puntualiza, además, que el endoso de esa persona determinada no hace falta para negociar el documento. El mecanismo para la aplicación en la práctica de esa disposición, que prevé una transmisión anónima del documento transmisible electrónico, quizá merezca un examen cuidadoso.

33. La cancelación del documento transmisible electrónico tras la presentación del documento y la ejecución por el deudor constituyen aspectos fundamentales del ciclo vital del documento transmisible electrónico. La obligación de cancelarlo puede ser satisfecha directamente por el tenedor, si esa es la manera en que se ejerce el control, o mediante la cooperación de un tercero, el administrador del registro. El tenedor y el administrador del registro pueden estar obligados a archivar de manera segura el documento electrónico una vez cancelado durante el plazo que fije el derecho sustantivo (por ejemplo, el artículo 86 de la ERMCA del Japón).

34. Se han redactado normas detalladas para la cancelación de los documentos archivados en sistemas de registro. El artículo 4 de la ERMCA enumera diversas

¹² A/CN.9/737, párr. 80.

¹³ *Ibid.*, párr. 67.

causas para la cancelación de un documento electrónico relacionadas con la ejecución parcial o total de la obligación: pago, compensación y fusión.

35. La legislación de la República de Corea sobre conocimientos de embarque electrónicos también contiene disposiciones específicas sobre la presentación del conocimiento de embarque electrónico para la entrega de las mercancías. El tenedor del conocimiento de embarque electrónico pide la entrega de las mercancías al porteador por conducto del administrador del registro. La intervención del administrador del registro es necesaria para enmendar el documento electrónico, a fin de evitar que siga circulando, y para transmitir la solicitud de entrega al porteador. Una vez verificada la validez de la solicitud, el porteador comunica al administrador del registro su aceptación de la solicitud de entrega y entrega las mercancías. Una vez efectuada la entrega, el porteador transmite al administrador del registro el nombre de la persona que recibió la mercadería y la fecha de la entrega efectiva. El administrador del registro cancela entonces el documento electrónico y comunica la cancelación al porteador y al destinatario¹⁴.

36. La legislación de la República de Corea sobre pagarés electrónicos contiene disposiciones similares. La presentación del pagaré electrónico se produce cuando el tenedor del pagaré transmite la solicitud de pago a la institución financiera responsable del pago del pagaré en nombre del deudor. Debe notificarse al administrador del registro el pago efectuado de manera que el pagaré electrónico pueda cancelarse¹⁵. Por consiguiente, el administrador del registro hace una anotación del pago del pagaré electrónico y transmite la nota al deudor¹⁶.

37. Puesto que la ejecución puede ser parcial, las disposiciones legislativas deberían abordar la cancelación parcial de los documentos transmisibles electrónicos y la constancia de esa ejecución parcial. La ejecución parcial podría abordarse también con el criterio seguido en los casos de los documentos fraccionados, creando un documento para lo que resta de la ejecución y cancelando el documento original.

38. Sin embargo, la legislación de la República de Corea sobre los pagarés electrónicos prohíbe expresamente el pago parcial de un pagaré electrónico¹⁷, en tanto que sí es posible el pago parcial de un pagaré de papel¹⁸. Este enfoque merece detenida consideración puesto que puede reducir el atractivo del uso de medios electrónicos en las operaciones comerciales y dar por resultado, también, la violación del principio de la no discriminación de las comunicaciones electrónicas.

39. La legislación pertinente debería tratar también de las circunstancias en que el deudor se niega a cumplir lo solicitado con la presentación del documento transmisible electrónico. Con respecto a los pagarés electrónicos, en la República de Corea la institución financiera que recibe el pagaré puede negarse a efectuar el pago (por ejemplo, por falta de fondos). La notificación al administrador del registro acerca de la negativa a pagar, y la anotación subsiguiente por el administrador de esa negativa en el pagaré electrónico, equivale al protesto certificado por notario

¹⁴ *Ibid.*, párrs. 38 a 40.

¹⁵ Artículos 9 y 10 de la Ley sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos.

¹⁶ Artículo 9 del Decreto Presidencial sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos.

¹⁷ Artículo 11 de la Ley sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos.

¹⁸ Artículo 39 de la Ley sobre Letras de Cambio y Pagarés, núm. 1001, de 1962, y enmiendas subsiguientes.

de los documentos de papel¹⁹. Después de la negativa a pagar, el pagaré electrónico queda cancelado²⁰. Sin embargo, según el derecho aplicable y los posibles usos del documento transmisible electrónico rechazado, puede resultar posible devolver el documento a su tenedor para una acción judicial ulterior (por ejemplo, contra un endosante o garante), en lugar de cancelarlo.

40. De modo análogo, según la legislación de la República de Corea sobre conocimientos de embarque electrónicos, en caso de negativa a entregar las mercancías, el porteador informará al administrador del registro acerca de sus razones. El administrador del registro, a su vez, comunicará esta negativa al tenedor del conocimiento de embarque electrónico²¹.

41. Por último, cabe observar que puede haber otras formas de cumplir la obligación (por ejemplo, mediante una compensación). En el artículo 22 de la ERMCA se prevé una norma especial para los casos en que el deudor adquiere un crédito monetario registrado electrónicamente y el artículo 23 se refiere a la extinción de la obligación y cancelación del documento electrónico conexo debido a la prescripción.

2. Conversión o reemplazo

42. La legislación existente recoge diversos enfoques en cuanto a la conversión de documentos de papel en documentos electrónicos y viceversa.

43. En un plano general, la legislación puede ser totalmente neutral respecto de los medios utilizados. La Ley por la que se establece un marco jurídico para la tecnología de la información (Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'Information) de Québec (Canadá) (L. R. Q., capítulo C-1.1) podría ser un buen ejemplo de ese enfoque. En el artículo 17 de esa Ley se define el concepto de documento en términos neutrales respecto de los medios utilizados, y ese enfoque permite convertir en cualquier momento un documento de papel en un documento electrónico y viceversa, sin que ello altere la condición jurídica del contenido del documento, siempre y cuando el procedimiento de conversión quede documentado con miras a asegurar la integridad de la información consignada en el documento.

44. Un enfoque más común consiste en recurrir a normas generales que establecen la equivalencia funcional entre los documentos electrónicos y los de papel, similares a las contenidas en los textos de la CNUDMI, por ejemplo, el artículo 6 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, y las subsiguientes disposiciones inspiradas por ese artículo. El artículo 17 5) de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico proporciona uno de los primeros ejemplos de disposición sobre la conversión entre distintos soportes de los documentos negociables electrónicos y los documentos utilizados en la esfera del transporte.

45. El artículo 10 de las Reglas de Rotterdam trata del reemplazo de un documento de transporte negociable o de un documento de transporte electrónico negociable. El reemplazo se produce si existe acuerdo entre el tenedor del documento de papel o

¹⁹ Artículo 12 2) de la Ley sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos y artículo 10 2) del Decreto Presidencial sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos.

²⁰ Artículo 10 3) del Decreto Presidencial sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos.

²¹ A/CN.9/692, párr. 41.

electrónico existente y el porteador (es decir, el deudor y el emisor, en el sentido jurídico si no tecnológico, del documento transmisible electrónico). En tal caso, el documento de papel o electrónico que ha de reemplazarse es entregado por el tenedor al porteador (con todas las copias, si hay originales múltiples del documento de papel). Ese documento de papel o electrónico queda cancelado y deja de tener efecto o validez. El porteador emite directamente o a través de un tercero un nuevo documento de papel o electrónico, usando el medio deseado, que incluye una declaración de que se reemplaza con él el documento anterior consignado en un medio diferente.

46. En el artículo 7-105 del Código de Comercio Uniforme así como en la legislación de la República de Corea sobre los conocimientos de embarque electrónicos se prevén normas similares sobre la nueva emisión en otro medio²².

47. Otro elemento contenido en el artículo 7-105 d) 2) del Código de Comercio Uniforme se refiere al requisito de que la persona que pide la emisión del documento electrónico debe garantizar a todas las personas subsiguientes que tengan derechos con arreglo al documento electrónico que esa persona ejercía el control sobre el documento de papel cuando cedió el control del documento para su conversión. Se aplica una disposición similar, *mutatis mutandis*, en el caso de sustitución de un documento electrónico por un documento de papel²³.

48. Como ya se dijo²⁴, el mecanismo para la compensación bancaria electrónica (truncamiento) de los cheques ideado en la Ley de Cheques XXI procura sustituir el cheque de papel por su imagen digital o el impreso de esa imagen, el cheque sustituto. El artículo 4 de la Ley de Cheques XXI dispone que, para que un cheque sustituto sea el equivalente legal del cheque original de papel para todos los fines, debe reproducir exactamente toda la información contenida en la cara y al dorso del cheque de papel en el momento en que se efectuó el truncamiento e incluir la siguiente declaración: “Esta es una copia legal de su cheque. Puede usarlo de la misma manera en que usaría el cheque original”.

49. Entre los datos que han de reproducirse en el cheque sustituto figura la línea de reconocimiento de caracteres de tinta magnética (MICR), identificador único del cheque que es, en los cheques de papel, de carácter magnético y por tanto legible por máquina²⁵. Además, el cheque sustituto deberá contener todos los endosos e identificar al banco reconvertidor, el banco emisor del cheque sustituto o, si el cheque sustituto no fue emitido por un banco, el primer banco que transfirió o presentó ese cheque sustituto²⁶. En realidad, el truncamiento puede darse en una de las etapas iniciales del ciclo de procesamiento del cheque puesto que la Ley de Cheques XXI permite depositar en el banco la imagen electrónica del cheque de papel²⁷.

²² *Ibid.*, párr. 37.

²³ Artículo 7-105 b) 2) del Código de Comercio Uniforme.

²⁴ A/CN.9/WG.IV/WP.118, párrs. 48 y 49.

²⁵ Artículo 3 16) B) de la Ley de Cheques XXI.

²⁶ Artículo 4 c) y d) de la Ley de Cheques XXI.

²⁷ Los aspectos jurídicos del proceso denominado “captura de depósitos remotos”, se examinan en J. Kopchik, “Remote Deposit Capture: A Primer”, 6 *Supervisory Insights* 1 (2009), 19 a 24.

3. Cancelación

50. Una vez cumplida la obligación contenida en el documento transmisible electrónico, este debe cancelarse para evitar su ulterior circulación y posibles pedidos múltiples de ejecución. De manera análoga a lo que sucede en el entorno de papel, el control sobre el documento transmisible electrónico se cede al deudor o a un tercero en nombre de ese deudor.

51. El artículo 9-208 b) 3) del Código de Comercio Uniforme establece las disposiciones aplicables a los valores mobiliarios electrónicos (*chattel papers*) cuando no existe una obligación garantizada pendiente y la parte garantizada no está comprometida a efectuar adelantos, contraer obligaciones o de otro modo dar una contraprestación²⁸.

52. La cancelación de un documento transmisible electrónico en un sistema de registro se produce cuando se hace constar en el documento la plena ejecución de la obligación. En el artículo 24 1) de la ERMCA del Japón se enumeran los datos que deben figurar en esa anotación: causa de la ejecución (pago, compensación, fusión, etc.); suma objeto de la ejecución (incluido el principal); identificación del ejecutante (si se trata de un tercero, incluir la razón de la ejecución); y fecha de la ejecución.

53. En la legislación de la República de Corea sobre pagarés electrónicos se prevé un mecanismo similar. Una vez efectuado el pago del pagaré electrónico, se hace una anotación del pago en el documento de ese pagaré electrónico y el administrador del registro transfiere el control sobre el documento anotado al emisor del pagaré electrónico²⁹.

54. Una vez cancelado el documento, su custodio, es decir el deudor o un tercero, según el sistema elegido, tiene el deber de conservarlo para fines de archivo. El plazo de retención del documento puede especificarse en la ley³⁰ y debería estar en

²⁸ Artículo 9-208 b) [Deberes de la parte garantizada después de recibir el requerimiento del deudor]

Dentro de un plazo de diez días después de recibir un requerimiento autenticado del deudor:

...

“(3) una parte asegurada distinta del comprador, que ejerza control sobre el valor mobiliario electrónico con arreglo al artículo 9-105 deberá:

A) transmitir el ejemplar fehaciente del valor mobiliario electrónico al deudor o a su custodio designado;

B) si el deudor designa a un custodio que sea el custodio designado en cuyo poder se mantiene el ejemplar fehaciente del valor mobiliario electrónico para la parte garantizada, transmitir al custodio un documento autenticado por el cual exima al custodio designado de toda obligación ulterior de cumplir con las instrucciones emanadas de la parte garantizada e imparta instrucciones al custodio de cumplir con las instrucciones emanadas del deudor;

C) adoptar las medidas apropiadas para permitir que el deudor o su custodio designado haga copias o revisiones del ejemplar fehaciente que agreguen o modifiquen un cesionario determinado del ejemplar fehaciente sin consentimiento de la parte garantizada;”.

²⁹ Artículo 10 de la Ley sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos y artículo 9 del Decreto Presidencial sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos.

³⁰ Artículo 86 de la ERMCA del Japón y artículo 13 del Decreto Presidencial de la República de Corea sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos; legislación de la República de Corea sobre conocimientos de embarque electrónicos (A/CN.9/692, párr. 46).

consonancia con lo que se prescribe para los documentos equivalentes de papel. El artículo 10 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico proporciona orientación sobre la retención de los documentos electrónicos.

IV. Otras cuestiones relacionadas con los documentos transmisibles electrónicos

A. El administrador del registro de documentos transmisibles electrónicos como tercero

55. Una característica de los sistemas de registro es la presencia de un tercero, el administrador del registro. Por consiguiente, las leyes que prevén el uso de registros electrónicos contienen disposiciones específicas sobre los administradores de registro.

56. Una de las cuestiones que se plantean es la existencia de un sistema de otorgamiento de licencias para la administración de los registros electrónicos. Se prevé un sistema de este tipo en la legislación de los Estados Unidos de América sobre resguardos de almacén electrónicos³¹, el artículo 51 de la ERMCA del Japón y la legislación de la República de Corea sobre los conocimientos de embarque³² y pagarés electrónicos³³. El sistema de otorgamiento de licencias es compatible con la existencia de un solo administrador o de varios administradores.

57. En los casos en que se prevé un sistema de otorgamiento de licencias, se designa una autoridad no solo para la aprobación de las licencias sino también para la supervisión del desempeño de los administradores de registro licenciados. La ley pertinente puede imponer un mínimo de requisitos para los aspirantes a obtener una licencia para la administración de registros. Entre esos requisitos puede figurar el de disponer de capital, estar constituido en un tipo determinado de sociedad y disponer de los recursos tecnológicos, financieros, humanos y de otra índole que hayan de destinarse a la empresa³⁴. También puede exigirse un seguro de cobertura de daños y perjuicios causados por errores y omisiones o fraude o dolo³⁵. A este respecto cabe observar que el artículo 10 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas contiene una lista de los factores pertinentes para establecer la fiabilidad de la certificación de los proveedores de servicios.

58. El administrador del registro puede ser responsable de daños y perjuicios causados por el funcionamiento del registro, pero dicha responsabilidad puede estar limitada por ley o por estipulaciones contractuales. Los artículos 11 y 14 de la ERMCA del Japón tratan, respectivamente, de la responsabilidad por errores del administrador del registro en la creación, enmienda y cancelación de documentos electrónicos, y en la emisión de documentos electrónicos basada en la solicitud de una entidad que no es legítima. En ambos casos, la norma de responsabilidad

³¹ Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos, título 7, artículos 735 a 401.

³² A/CN.9/692, párr. 42.

³³ Artículo 3 de la Ley de la República de Corea sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos.

³⁴ Artículos 3 y 4 del Decreto Presidencial de la República de Corea sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos (A/CN.9/692, párr. 42).

³⁵ Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos, título 7, artículos 735 a 401 2).

contiene una inversión de la carga de la prueba y el administrador del registro puede quedar exento de la obligación de demostrar que no hubo negligencia.

59. También se imponen obligaciones a los usuarios del registro electrónico. Estas obligaciones suelen quedar definidas contractualmente en acuerdos de prestación de servicios. Especialmente pertinente puede ser la obligación de los usuarios de mantener un acceso seguro al sistema, así como las obligaciones relacionadas con la pronta actualización de las modificaciones de la información sobre el usuario, como se prescribe en la legislación de la República de Corea sobre los conocimientos de embarque electrónicos³⁶. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a responsabilidad³⁷. A su vez, el administrador del registro tiene la obligación de informar a los usuarios acerca de las condiciones generales del contrato³⁸.

60. Puede establecerse un mecanismo especial para la resolución de las controversias que puedan surgir del uso del registro electrónico³⁹.

B. Reconocimiento transfronterizo de los documentos transmisibles electrónicos

61. En el 45º período de sesiones de la Comisión, se insistió en la necesidad de contar con un régimen internacional para facilitar el uso transfronterizo de los documentos transmisibles electrónicos⁴⁰.

62. Si bien existen ejemplos de leyes nacionales que permiten el uso comercial satisfactorio de documentos transmisibles electrónicos, pueden presentarse obstáculos jurídicos en el contexto transfronterizo, en el caso de países que no hayan desarrollado completamente un mercado de ese tipo. Esos obstáculos pueden abordarse convenientemente mediante normas internacionales uniformes sobre los aspectos internacionales del uso de documentos transmisibles electrónicos.

63. Ejemplo de un instrumento internacional que prevé explícitamente el uso de documentos transmisibles electrónicos es el de las Reglas de Rotterdam, si bien su uso se limita a los documentos de transporte electrónicos.

64. Desde el punto de vista del derecho relativo a las operaciones electrónicas, la labor precursora realizada por la CNUDMI se centró inicialmente en la preparación de leyes modelo uniformes. Ese enfoque permitió la armonización de los ordenamientos jurídicos nacionales carentes de un mecanismo oficial para el reconocimiento de las comunicaciones electrónicas extranjeras. De este modo, la

³⁶ A/CN.9/692, párrs. 43 a 45.

³⁷ Artículo 8 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas relativo al proceder del firmante.

³⁸ Artículo 18 de la Ley de la República de Corea sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos y artículo 15 del Decreto Presidencial de la República de Corea sobre la Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos.

³⁹ Artículo 16 del Decreto Presidencial de la República de Corea sobre Emisión y Negociación de Pagarés Electrónicos.

⁴⁰ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, Sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17)*, párr. 83. En el 45º período de sesiones del Grupo de Trabajo, se observó que el texto o los textos que habían de prepararse deberían abordar las cuestiones relacionadas con el reconocimiento transfronterizo de los documentos transmisibles electrónicos (A/CN.9/737, párr. 44).

Ley Modelo sobre Comercio Electrónico ha tenido un éxito notable; en efecto, ya ha sido adoptada por más de 40 Estados y ha inspirado legislación regional. Sin embargo, la Ley Modelo no contiene disposiciones explícitas sobre las operaciones transfronterizas. Eso también vale para su artículo 17, que ofrece uno de los primeros ejemplos de tratamiento de los documentos transmisibles electrónicos⁴¹.

65. La ausencia de disposiciones específicas para la aplicación transfronteriza no impide la incorporación a las legislaciones nacionales de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico y su aplicación a las operaciones transfronterizas⁴². El hecho de que esos casos todavía sean raros no debe tomarse necesariamente como indicio de que las comunicaciones electrónicas sean de pertinencia limitada para el comercio internacional. De hecho, la experiencia sugiere la conclusión opuesta. En realidad, la jurisprudencia relativamente escasa podría deberse a que se ha prestado poca atención a la reunión de esos casos, que normalmente se comunican en relación con cuestiones jurídicas surgidas en otras esferas jurídicas (por ejemplo, la compraventa de mercancías). Además, en ciertos ordenamientos jurídicos, especialmente los de países de tradición anglosajona, puede suceder que se considere que las cuestiones jurídicas relacionadas con el uso de las comunicaciones electrónicas no se prestan a controversia y, por tanto, no se plantean en los litigios.

66. El artículo 12 de la Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas, que trata del reconocimiento de firmas electrónicas extranjeras, ofrece un ejemplo de disposición modelo uniforme dedicada exclusivamente a las cuestiones transfronterizas. Este artículo adopta un enfoque neutral respecto de la tecnología utilizada y se basa en el principio de la no discriminación geográfica. Sin embargo, el artículo no se ha incorporado todavía de manera general a las legislaciones nacionales y es posible encontrar otras disposiciones modelo basadas en enfoques más prescriptivos (por ejemplo, el artículo 7 de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica⁴³; esta Directiva es actualmente objeto de examen⁴⁴.

67. La conveniencia de abordar las cuestiones transfronterizas, especialmente las originadas en la aplicación de acuerdos internacionales redactados antes del uso generalizado de las comunicaciones electrónicas, fue una de las razones que

⁴¹ A/CN.9/WG.IV/WP.118, párr. 15.

⁴² Véase, por ejemplo, Federal Court of Australia, *Olivaylle Pty Ltd v Flottweg GMBH & Co KGAA*, [2009] FCA 522 (caso de la jurisprudencia de los tribunales sobre textos de la CNUDMI) (CLOUT núm. 956); Alto Tribunal Comercial de Ucrania, case núm. 2009/17/140-3571 (9/56-1492): LLC Horizont Marketing-Finance-Logistika v. LLC Terkyrii-2 (caso CLOUT núm. 1051).

⁴³ Puede consultarse en:

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/other_policies/124118_en.htm.

⁴⁴ El 4 de junio de 2012, la Comisión Europea aprobó una propuesta de “Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo sobre la identificación electrónica y los servicios de fiabilidad para las operaciones electrónicas en el mercado interno”. El nuevo marco procura garantizar la aceptación y el reconocimiento mutuos de la identificación electrónica a través de las fronteras y de dar efecto legal y reconocimiento mutuo a los servicios de fiabilidad, incluido el mejoramiento de las actuales normas sobre firmas electrónicas y la elaboración de un marco jurídico para el estampado de sellos electrónicos, el marcado cronológico, la aceptabilidad de documentos electrónicos, la entrega electrónica y la autenticación de sitios web. Puede consultarse el texto de la propuesta y demás información en http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm.

llevaron a la preparación y adopción de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas. Si bien la Convención entrará en vigor el 1 de marzo de 2013, el ritmo de su adopción por los Estados ha sido más lento de lo que se preveía⁴⁵. Se han mencionado varias razones que explican esa tendencia, incluida la conciencia limitada de la necesidad de la Convención y, por tanto, el interés también limitado en su adopción, en el sector comercial y jurídico, y las dificultades relacionadas con la coordinación de la posición de las organizaciones regionales de integración económica de manera que la Convención pueda ser adoptada por los Estados miembros de esas organizaciones.

68. Además, la evaluación de la influencia real de esa Convención en el derecho mundial de las operaciones electrónicas debería tener en cuenta que varios países en desarrollo han adoptado disposiciones sustantivas de la Convención pese a no haberla ratificado oficialmente. Esto puede deberse a varias razones, incluida la dificultad de coordinar el proceso interno de preparación de legislación sobre operaciones electrónicas con la ratificación oficial de un instrumento internacional, y la falta de una influencia indirecta de la adopción más amplia de la Convención por ordenamientos jurídicos que se perciben como más avanzados en el empleo de las comunicaciones electrónicas para fines comerciales transfronterizos.

69. El artículo 20 de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas tiene un efecto habilitante explícito de varios tratados preparados por la CNUDMI; sin embargo, no menciona entre los tratados enumerados la Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagarés Internacionales, de 1988, ni el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, de 1978 (“Reglas de Hamburgo”), debido a que ambos tratados se ocupan del equivalente de papel de los documentos transmisibles electrónicos⁴⁶. Por consiguiente, se excluyeron los documentos transmisibles electrónicos del ámbito de aplicación de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas (artículo 2, párrafo 2). Un mecanismo posible para colmar esa laguna podría consistir en la preparación de un protocolo de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas que se ocupe específicamente de los documentos transmisibles electrónicos. Ese protocolo podría contener también, si así se desea, normas sobre aspectos del derecho internacional privado.

70. Otras consideraciones útiles en la formulación de una política sobre los aspectos transfronterizos de los documentos transmisibles electrónicos guardan relación con la experiencia de los dos sectores más directamente interesados en el empleo de esos documentos, a saber, el transporte marítimo y los servicios financieros.

71. En la esfera del derecho marítimo, la posibilidad del empleo transfronterizo de documentos de titularidad consignados en papel ha sido, históricamente, uno de los principales motivos para la preparación de instrumentos internacionales, como el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos de embarque, de 1924 (“Reglas de La Haya”). En fecha más reciente, uno de los principales objetivos perseguidos por las Reglas de Rotterdam ha sido

⁴⁵ Véase el comunicado de prensa en www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2012/unis1172.html. Puede consultarse el estado de la Convención en www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.status.html.

⁴⁶ A/CN.9/527, párrs. 45 y 65.

dar cabida al empleo transfronterizo de los documentos de transporte electrónicos negociables.

72. En la esfera de los servicios financieros y, más específicamente, de los títulos negociables, las tentativas de armonizar el marco jurídico internacional ha tenido un éxito limitado. En particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagarés Internacionales no ha entrado todavía en vigor. Es posible que la evaluación de las actuales necesidades y prácticas de ese sector comercial requiera mayor atención.

73. En conclusión, existen varias posibilidades para superar los obstáculos jurídicos que se oponen al empleo transfronterizo de las leyes nacionales sobre documentos transmisibles electrónicos. Entre las opciones disponibles cabe mencionar la preparación de disposiciones uniformes u otros textos de orientación sobre los problemas transfronterizos, y la preparación de un instrumento jurídico internacional vinculante. La elección de las soluciones apropiadas puede variar también según el sector comercial de que se trate.

C. Nota de la Secretaría sobre cuestiones jurídicas relativas a la utilización de documentos transmisibles electrónicos — Propuesta de los Gobiernos de Colombia, España y los Estados Unidos, presentada al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 46° período de sesiones

(A/CN.9/WG.IV/WP.119)

[Original: inglés]

En el marco de los preparativos para la realización del 46° período de sesiones del Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico), los Gobiernos de Colombia, España y los Estados Unidos presentaron a la Secretaría el documento adjunto.

El documento que se adjunta como anexo se reproduce en la forma en que fue recibido por la Secretaría.

Anexo

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción.	1-4
II. Documentos transmisibles electrónicos	5-15
III. Examen previo en la CNUDMI de la cuestión de los documentos transmisibles electrónicos	16-20
IV. Cuestiones que debe examinar el Grupo de Trabajo	21-45
V. Sectores que podrían beneficiarse de la labor en esa esfera	46-53

I. Introducción

1. En su 45° período de sesiones, celebrado en Viena del 10 al 14 octubre de 2011, el Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) instó a los Estados miembros a que facilitaran a la Secretaría información pertinente para ayudarla a preparar los documentos de trabajo para su siguiente período de sesiones¹. A tal fin las delegaciones de Colombia, España y los Estados Unidos de América han preparado el presente documento.

2. En su 45° período de sesiones el Grupo de Trabajo señaló que no había un marco jurídico internacionalmente aceptado, generalizado y armonizado que regulara los documentos transmisibles electrónicos². Sin embargo, según puede verse en el presente documento de trabajo, los documentos transmisibles electrónicos se utilizan en la actualidad en diversas operaciones comerciales, nacionales e internacionales, y muchas de las cuestiones jurídicas relacionadas con

¹ Véase el párr. 95 del documento A/CN.9/737.

² Véase el párr. 14 del documento A/CN.9/737.

ellos ya han sido tratadas y resueltas en normas nacionales e internacionales³. Lo que falta es un grado suficiente de armonización a nivel transfronterizo para lograr una mayor eficacia en las operaciones, la financiación y el comercio a nivel internacional. Estos ejemplos podrían servir de modelo para la labor del Grupo de Trabajo, que tiene ahora la oportunidad de preparar normas internacionales que conferirían certeza jurídica al empleo de un documento transmisible electrónico.

3. Es precisamente el éxito logrado en varios sistemas nacionales lo que ha sugerido la necesidad de contar con un marco jurídico internacionalmente reconocido para este tipo de documentos. Sin un marco jurídico internacional el creciente ámbito del comercio internacional no puede aprovechar los beneficios logrados mediante los sistemas nacionales⁴.

4. También es importante observar que el uso de los documentos transmisibles electrónicos solo es parte de un conjunto más amplio de temas jurídicos relacionados con el comercio electrónico. Entre esos temas se cuentan la gestión de datos de identificación personal y el sistema de ventanilla electrónica única⁵. Es por eso que el examen que hace actualmente el Grupo de Trabajo de los documentos transmisibles electrónicos no excluye los otros temas importantes en la esfera del comercio electrónico sino que, en realidad, forma parte de un proyecto más amplio y general sobre el comercio electrónico.

II. Documentos transmisibles electrónicos

A. Documentos transmisibles

5. “Documento transferible” es un término general que se refiere tanto a un título transferible como a un documento de titularidad transferible. Un documento transmisible electrónico es el equivalente electrónico de un documento transferible.

6. Los títulos transmisibles son instrumentos financieros que pueden contener una promesa incondicional o una orden a un tercero de pagar una cantidad determinada de dinero al tenedor del título. Como ejemplos de títulos transmisibles cabe mencionar los pagarés, las letras de cambio, los cheques y los certificados de depósito.

³ Véase el documento A/CN.9/WG.IV/WP.115.

⁴ Si bien los problemas comerciales prácticos que presentan los documentos transmisibles electrónicos generalmente son similares en distintos países, parte del desafío será lograr una norma jurídica internacional común que sea aceptable para las distintas tradiciones jurídicas. Como observó el Grupo de Trabajo en su último período de sesiones esto no presentará mayor problema, ya que las normas que regulan los documentos transmisibles generalmente son similares en las distintas tradiciones jurídicas (véase el párr. 53 del documento A/CN.9/737). Además, como la legislación de fondo que rige los documentos transmisibles es suficientemente sólida el Grupo de Trabajo debería concentrarse en proveer un mecanismo para que esas normas sustantivas vigentes pudieran aplicarse en un medio electrónico.

⁵ Por ejemplo, el estudio de la responsabilidad de los terceros de confianza y de otros prestadores de servicios es un tema que no solamente tiene relación con los documentos transmisibles electrónicos sino también con la gestión de datos de identificación personal y el sistema de ventanilla electrónica única.

7. Los documentos de titularidad transmisibles son documentos que, en el curso ordinario de los negocios o de la financiación, constituyen una prueba fehaciente de que el tenedor o el titular del documento tienen derecho a recibir, conservar y disponer de él y de las mercancías allí representadas (a reserva de las excepciones que quepa oponer a la ejecución del documento). Como ejemplo de documentos de titularidad cabe citar algunos documentos de transporte, conocimientos de embarque, resguardos de almacén de depósitos en muelle, resguardos o recibos de muelle, recibos de almacén u órdenes de entrega de mercancía.

8. La distinción fundamental entre un título y un documento de titularidad es que el título representa dinero mientras que el documento de titularidad representa mercancía. Por ejemplo, un pagaré es un título transferible que da fe de la obligación de pagar una deuda. Un recibo de almacén negociable es un documento de titularidad que obliga al encargado del almacén a entregar al tenedor del recibo las mercancías almacenadas en su establecimiento.

B. Distinción entre negociable y no negociable

9. El título transferible y el documento de titularidad transferible pueden ser negociables o no negociables. Un documento transferible es negociable cuando, por las condiciones estipuladas, se paga dinero (título) o se entregan mercancías (documento) al portador o a la persona cuyo nombre consta en el documento. Vale decir que su característica esencial es la posibilidad de transmitir los derechos sobre el dinero o las mercancías con la tradición del documento. Un documento transferible que no confiere estos derechos es un documento no negociable.

10. Normalmente un documento transferible puede negociarse (los derechos pasan con el documento) en forma independiente de los derechos que nacen de la transacción subyacente. En otras palabras, los derechos que se adquieren con la negociación de un documento transferible no están sujetos a las excepciones que nacen de la transacción subyacente que fue la base de la creación de dicho documento transferible⁶. Esta capacidad de transmitir los derechos incorporados en el documento libres de las excepciones subyacentes es la diferencia esencial entre la transmisión de un documento transferible y la negociación de un documento transferible.

C. Documentos transmisibles electrónicos

11. Tradicionalmente tanto los títulos transmisibles como los documentos de titularidad transmisibles han sido en papel. Pero en la actualidad hay modelos de documentos transmisibles en formato electrónico que están vigentes o en desarrollo en varios ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.

⁶ Por ejemplo, cuando un comprador abona la mercancía con un pagaré el hecho de que el comprador tenga un derecho contra el vendedor por defectos en la mercancía no afectará los derechos del tenedor del pagaré. El comprador no podrá accionar contra el tenedor por la calidad de esa mercancía.

12. Por ejemplo, la legislación de los Estados Unidos regula determinados títulos electrónicos transmisibles que son negociables⁷. También regula los documentos transmisibles electrónicos que son negociables⁸. El empleo de documentos transmisibles electrónicos ya lleva casi 20 años en los Estados Unidos, con reglamentaciones federales que regulan el uso de recibos electrónicos de almacenamiento en la industria del algodón⁹.

13. Las medidas adoptadas en algunos países señalan la utilidad y los beneficios de emplear documentos electrónicos negociables o transmisibles. Corea ha promulgado legislación y ha creado la infraestructura necesaria para generar títulos electrónicos basados en un registro. La ley del Japón sobre reclamaciones monetarias registradas electrónicamente¹⁰ establece qué se considera una réplica electrónica o un sustituto electrónico de los títulos negociables en papel. Esta legislación, con la correspondiente infraestructura basada en un registro, regula un nuevo concepto (las reclamaciones monetarias registradas electrónicamente) que, si bien se han tipificado como una nueva categoría de derechos individuales que se corresponden con una deuda pecuniaria (incluidas las cuentas por cobrar) operará en muchos aspectos como un instrumento financiero electrónico y reemplazará a los instrumentos en papel con una alternativa más rápida, más funcional y más útil¹¹. Estas reclamaciones pecuniarias negociables documentadas en forma electrónica constituyen un instrumento financiero más flexible, no solo por su formato electrónico (con todas las ventajas que de ello se derivan), sino también porque el régimen sustantivo para negociarlos ha sido modificado y adaptado ligeramente para aprovechar las ventajas del medio electrónico. En esa medida se espera que este sistema revolucione la financiación mercantil, especialmente en el caso de las empresas pequeñas y medianas.

14. Colombia también ha promulgado legislación a este respecto. La normativa vigente sobre el comercio electrónico establece el reconocimiento de los documentos electrónicos y de las firmas electrónicas. Estas normas se basan, en gran medida, en las leyes modelo de la CNUDMI. Las normas del comercio electrónico ya permiten la emisión y el archivo de facturas comerciales en forma

⁷ Véase el artículo 16 de la Ley Uniforme de operaciones electrónicas. Solo regula los pagarés electrónicos (instrumentos en el que intervienen dos partes) y no los títulos electrónicos en los que intervienen tres partes (por ejemplo, los cheques y las órdenes de pago). Los pagarés electrónicos también están regulados por la Ley de Firma Electrónica en el Comercio Mundial y Nacional, 15 U.S.C. §§ 7001-7031; sin embargo, en esta norma el uso del pagaré electrónico está limitado a las operaciones inmobiliarias. Los títulos electrónicos transmisibles en los que intervienen tres partes no están regulados por ninguna de las dos leyes. Sin embargo, a los fines de una transferencia casi instantánea de fondos, esto se ha logrado por el uso habitual de las transferencias bancarias. También es usual hoy en día, y sigue evolucionando, la utilización del clearing electrónico (el empleo de una copia digital en lugar del instrumento original en el sistema de cobros interbancarios).

⁸ Véase la Ley Uniforme de operaciones electrónicas de los Estados Unidos (artículo 16), el Código de Comercio Uniforme (artículo 7: Documento de titularidad), y la Ley de almacenes.

⁹ Véase el Código de Reglamentaciones Federales de los Estados Unidos, Título 7 – Agricultura, parte 735 – Reglamentaciones para la Ley de almacenes de los Estados Unidos.

¹⁰ Ley núm. 102, de 27 de junio de 2007.

¹¹ La reclamación monetaria registrada electrónicamente se crea en un documento electrónico que se inscribe en una institución y que es transmisible a terceros. Esta transmisión es, en principio, equivalente a una negociación.

electrónica¹². Una característica particular de la legislación colombiana es que la factura comercial en papel se considera un título negociable. Una factura comercial puede, por lo tanto, transmitirse con todas las consecuencias propias de su carácter negociable, lo que facilita el acceso del emisor a los servicios financieros basados en el descuento de facturas. Por lo tanto la legislación colombiana también permite la emisión y transmisión de facturas electrónicas como un título valor negociable¹³. Hay un proyecto de reglamentación de la emisión y negociación de facturas electrónicas. Este proyecto ha dado una clara indicación del interés y los beneficios de contar con normas sobre documentos transmisibles electrónicos tanto para el sector comercial como para el financiero. Si bien todavía no se han aprobado normas específicas sobre esta cuestión, y precisamente dado el mandato otorgado por la Comisión al Grupo de Trabajo, el decreto 19 (de 10 de enero de 2012) del Gobierno Nacional modifica la legislación colombiana sobre el comercio electrónico para permitir que las entidades de certificación emitan certificados para la utilización de documentos transmisibles electrónicos, como así también presten servicios para su registro, custodia, anotación y archivo.

15. También hay un creciente cuerpo de derecho internacional que reconoce los documentos transmisibles electrónicos. Como se afirma más adelante, esto incluye los textos de la CNUDMI¹⁴. Es importante destacar que en su labor relacionada con las Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (Convención sobre Comunicaciones Electrónicas) el Grupo de Trabajo decidió expresamente no incluir los documentos transmisibles en su ámbito de aplicación¹⁵. Se espera que el Grupo de Trabajo pueda ahora completar esa labor sobre los documentos transmisibles, que había postergado.

III. Examen previo en la CNUDMI de la cuestión de los documentos transmisibles electrónicos

16. El Grupo de Trabajo ha tenido en estudio el tema de los documentos transmisibles electrónicos prácticamente desde que comenzó a ocuparse de los temas relacionados con el comercio electrónico. Si bien el Grupo de Trabajo ha destacado y analizado la pertinencia de este tema en diversas ocasiones, una línea de trabajo específica ha sido aplazada reiteradamente por diferentes razones.

17. Al preparar la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, de 1996, el Grupo de Trabajo se ocupó de los documentos transmisibles electrónicos en una etapa más bien tardía¹⁶. Inmediatamente se percibieron los problemas que ocasionaría la reglamentación de la réplica electrónica de títulos o documentos negociables, y

¹² Ley núm. 962, de 8 de julio de 2005.

¹³ Ley núm. 1231, de 17 de julio de 2008.

¹⁴ La ley Modelo sobre Comercio Electrónico (1996) y el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo (2008).

¹⁵ Véase el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas: “La presente Convención no será aplicable a las letras de cambio, pagarés, cartas de porte, conocimientos de embarque o resguardos de almacén, ni a ningún documento o título transmisible que faculte a su portador o beneficiario para reclamar la entrega de las mercancías o el pago de una suma de dinero”.

¹⁶ Véase el párr. 177 del documento A/CN.9/387; y los párrs. 178 y 179 del documento A/CN.9/406.

resultó evidente que la mera formulación de los principios generales para la neutralidad de los medios no solucionaría todas las dificultades ni las cuestiones conexas. Sin embargo se propuso incluir en la Ley Modelo un artículo que tratara de los documentos de transporte negociables, que en algunas jurisdicciones hacen las veces de documentos de titularidad de las mercancías. La industria del transporte había comenzado a emplear versiones electrónicas de los documentos de transporte negociables, pero esto se daba sin un sistema regulatorio¹⁷. Sobre esta base, los artículos 16 y 17 de la Ley Modelo contienen un modelo de reglamentación para el uso de documentos electrónicos negociables en el contexto del contrato de transporte de mercancías¹⁸.

18. Dados los numerosos interrogantes planteados por los documentos transmisibles electrónicos, y los supuestos beneficios de un instrumento que trate este tema, el Grupo de Trabajo alentó la consideración de esta cuestión como un posible tema futuro. A este fin se publicaron algunos documentos, centrando el análisis nuevamente en los documentos de titularidad, pero al mismo tiempo ampliando el ámbito a los sistemas vigentes para la transmisión electrónica de derechos y de intereses sobre mercancías¹⁹.

19. Como el tema de los documentos transmisibles electrónicos es importante para el sector del transporte marítimo está tratado en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, de 2008, ("Reglas de Rotterdam"). Las Reglas de Rotterdam forman un marco jurídico para la utilización de documentos de transporte electrónicos (negociables y no negociables) que ha aprovechado extensivamente la labor y los debates de la CNUDMI sobre este tema y sobre los modelos que presentan algunas normas nacionales. Las Reglas de Rotterdam pueden resultar un marco útil para el Grupo de Trabajo cuando amplíe su labor sobre los documentos transmisibles. Sin embargo, estas reglas son solo uno de los modelos que merecerían la atención del Grupo de Trabajo, ya que solo tratan de los documentos de transporte y no se ocupan de los problemas que puedan tener una relación general con los títulos y documentos negociables²⁰.

20. Como se mencionó anteriormente (párr. 15 *supra*), también se examinó el tema de los documentos transmisibles electrónicos en ocasión de las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales. En esta Convención los documentos negociables se dejaron una vez más de lado, ya que en el artículo 2 quedaron

¹⁷ Véanse a este respecto las propuestas del Reino Unido (Anexo II al documento A/CN.9/WG.IV/WP.66) y las de los Estados Unidos de América (Anexo al documento A/CN.9/WG.IV/WP.67); los párrs. 115 a 117 del documento A/CN.9/407; y el documento A/CN.9/WG.IV/WP.69.

¹⁸ La Segunda Parte de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de 1996 ha servido de inspiración, por ejemplo, a la Tercera Parte de la Ley Uniforme de comercio electrónico del Canadá.

¹⁹ Véanse el párr. 106 del documento A/CN.9/421 y el documento A/CN.9/WG.IV/WP.90.

²⁰ Entre los sistemas cerrados, privados, de documentos electrónicos (documentos de transporte) está el sistema BOLERO (Organización del Registro Electrónico de los Conocimientos de Embarque), administrado por un consorcio de bancos, que ya ha madurado y puede resultar de utilidad para profundizar el estudio de los documentos transmisibles. La experiencia con BOLERO sugiere que, de examinar el Grupo de Trabajo cuestiones de registro, podría considerar los derechos de terceros oponibles al titular del derecho en un sistema registral.

expresamente excluidos del ámbito de aplicación²¹. Los principales motivos de esta exclusión fue considerar que excedía el mandato del Grupo de Trabajo, como así también la opinión de que todavía no se habían desarrollado plenamente los elementos esenciales de un régimen jurídico de los documentos transmisibles electrónicos²². El Grupo de Trabajo consideró que este tema era importante y había que profundizar su estudio. Por lo tanto la nota explicativa especifica: “la Convención no es aplicable a los instrumentos negociables ni a los documentos de titularidad, a causa de la especial dificultad que plantearía la creación de un equivalente electrónico de la negociabilidad de documentos sobre papel, para lo cual habría que formular reglas especiales”²³. La tarea que se ha encomendado ahora al Grupo de Trabajo es la continuación lógica y natural de una línea de trabajo que quedó inconclusa en otros períodos de sesiones; además, a este respecto han tenido lugar avances significativos en las legislaciones nacionales y en la práctica.

IV. Cuestiones que debe examinar el Grupo de Trabajo

A. Cuestiones señaladas en otros trabajos de la CNUDMI

21. En el curso de los debates sobre los instrumentos mencionados anteriormente fueron señaladas algunas de las cuestiones y los problemas que se deberán examinar en relación con las normas aplicables a los documentos transmisibles electrónicos. Algunos de ellos se relacionan directamente con las características que se deberían tener en cuenta en el marco jurídico para la emisión y utilización de documentos transmisibles electrónicos²⁴. Éstos se refieren a las condiciones necesarias para la creación de documentos transmisibles electrónicos, los tipos de documentos transmisibles negociables que puedan emitirse en formato electrónico (títulos financieros, documentos de titularidad, etc.), las condiciones de la transmisión, la identificación del tenedor y las normas requeridas a tal fin, así como la precisa determinación de los derechos incorporados en el documento (algo que, sin embargo, se refiere al aspecto sustantivo de los títulos negociables)²⁵.

22. También se plantearon cuestiones sobre problemas que pueden considerarse secundarios al tema de los documentos transmisibles electrónicos y comunes al empleo de medios electrónicos para fines comerciales, pero que sería muy conveniente que el Grupo de Trabajo las estudiara. Entre estos temas se cuentan la responsabilidad de terceros proveedores de servicios, la responsabilidad por errores en las comunicaciones realizadas mediante el empleo de “agentes electrónicos” (sistemas automatizados)²⁶ o, en general, la función y responsabilidad de los

²¹ Véase la nota 15 *supra*.

²² Véase el Texto-Nota explicativa, párr. 81, de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales.

²³ Véase el Texto-Nota explicativa, párr. 7, de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales. Véanse también los párrs. 88 y ss. del documento A/CN.9/484.

²⁴ Véase la sección IV b) del presente documento. Véanse también los párrs. 88 y ss. del documento A/CN.9/484.

²⁵ El Grupo de Trabajo no abordará el tema de los derechos sustantivos subyacentes en esos títulos y documentos.

²⁶ Véanse los párrs. 11 a 13 del documento A/CN.9/WG.IV/WP.104/Add.4.

terceros confiables y otros intermediarios en la transmisión de documentos o derechos (o en la ejecución de operaciones similares). La labor que podría realizar el Grupo de Trabajo en relación con estas cuestiones también beneficiaría a otras cuestiones claramente relacionadas con el uso de documentos transmisibles electrónicos, como por ejemplo la gestión de datos de identificación personal en un contexto electrónico (algo que es crucial para el carácter negociable en el espacio digital) o el cumplimiento de las formalidades documentales en las operaciones de exportación e importación (relacionados con la aduana y con la viabilidad de sistemas basados en una ventanilla electrónica única).

23. Con anterioridad el Grupo de Trabajo había examinado el régimen jurídico para el empleo de documentos transmisibles electrónicos en relación con otros temas, como por ejemplo la documentación comercial, vale decir el conocimiento de embarque, la gestión de datos de identificación personal, los sistemas de ventanilla electrónica única, etc., ya que todos ellos comparten numerosas cuestiones jurídicas. Estos temas conexos generalmente comprenden temas relacionados con la transmisión por un medio electrónico de derechos individuales o derechos de propiedad sobre bienes tangibles o intangibles²⁷. Cada uno de ellos tiene algún aspecto que será pertinente para el examen de cuestiones relativas a los documentos transmisibles.

B. Principios básicos

24. En las deliberaciones de su 45º período de sesiones el Grupo de Trabajo especificó al menos cinco principios básicos que son necesarios para los documentos transmisibles electrónicos: i) la equivalencia electrónica de la escritura; ii) la equivalencia electrónica de la firma; iii) la unicidad y la garantía de singularidad; iv) la transmisión de derechos; y v) la identificación y la autenticación del tenedor²⁸.

25. Para cada una de estas cuestiones hay modelos vigentes que el Grupo de Trabajo puede tener interés en considerar.

1. Escritura

26. Si bien probablemente sea una de las cuestiones menos problemáticas que deben abordarse, la cuestión del equivalente electrónico de la escritura es un elemento esencial del documento transmisible electrónico. En el pasado se entendía que los documentos transmisibles debían ser por escrito y estar firmados. La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico reconoce que la doctrina flexible del “equivalente funcional” basta para sustituir el requisito de que el documento sea por escrito²⁹. La Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales y las Reglas de Rotterdam también adoptan este principio³⁰. Esta conclusión está bien establecida

²⁷ Véanse el párr. 83 del documento A/CN.9/WG.IV/WP.69 y el párr. 61 del documento A/CN.9/421.

²⁸ Véase el documento A/CN.9/WG.IV/WP.115.

²⁹ Véanse los artículos 5 a 10 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico.

³⁰ Véanse la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales y las Reglas de Rotterdam.

en varias leyes nacionales de comercio electrónico, muchas de ellas inspiradas en la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la CNUDMI.

2. Firma

27. Como ocurre con la escritura, hay una copiosa legislación nacional e internacional que adopta para las firmas la norma del equivalente funcional, como por ejemplo la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales.

28. Sin embargo, también existen argumentos, por ejemplo en las Reglas de Rotterdam, para prescindir del requisito de la firma en el caso del documento transferible. En este último caso se presume que la función de la firma es probar el derecho de propiedad y de transmisión, y cuando rige el concepto de “control”, consagrado en estas normas, éste ya cumple esa función y no se requiere la firma.

29. Cualquiera de los criterios tiene mucho en su favor, y existen numerosos modelos funcionales tanto en el derecho internacional como en los derechos nacionales que el Grupo de Trabajo podrá analizar.

3. Unicidad y garantía de singularidad

30. Con los documentos transmisibles tradicionales en papel se presume que solo existe un ejemplar original y singular del documento³¹. Esta presunción no es necesariamente compatible con el documento transmisible electrónico. En la actualidad existen dos modelos que hacen a la unicidad y la garantía de singularidad de esos documentos: i) el sistema de registro y ii) el sistema de símbolos (*tokens*).

31. En el sistema de registro la creación, emisión y transmisión de un documento transmisible electrónico se inscriben en un registro central. Como el registro asienta los derechos del documento transmisible electrónico a favor de la parte que tiene esos derechos no hay razón para requerir un documento original y singular que los acredite. Además, en la medida en que la doctrina del control reemplaza la necesidad de la posesión material, como se expone más adelante, el registro también cumple el requisito del control.

32. Los sistemas de registro son muy comunes hoy en día y están bien desarrollados y son eficaces³². Por ejemplo, en los Estados Unidos el artículo 16 de la Ley Uniforme de operaciones electrónicas establece un sistema de registro para el empleo de títulos electrónicos transmisibles³³. El Código de Comercio Uniforme

³¹ Desde ya que existen numerosas disposiciones jurídicas que tratan del problema del fraude y la falsificación del documento en papel.

³² En el presente documento el examen queda limitado a los sistemas de registro para los documentos transmisibles electrónicos. También hay ejemplos de registros internacionales exitosos para las garantías reales. El más conocidos es el registro de aeronaves para la Convention on International Interests in Mobile Equipment (“Cape Town Convention”), que establece un registro para el fletamento y las garantías reales de las aeronaves. Otro ejemplo es el artículo 9 del Código Comercial Uniforme de los Estados Unidos: Operaciones seguras, artículos 9-105 (que regula los valores mobiliarios en formato electrónico), que fue promulgado en respuesta a solicitudes del sector de financiación de la industria automotriz para favorecer la utilización de documentos electrónicos.

³³ En los comentarios oficiales se señala que “un sistema basado en un registro administrado por

también ha regulado los valores mobiliarios en formato electrónico respondiendo a una solicitud del sector de financiación de la industria automotriz para que se fomenta su uso³⁴. Ambas leyes han favorecido el éxito de los documentos transmisibles electrónicos en los Estados Unidos.

33. La experiencia de los Estados Unidos con registros para documentos electrónicos negociables comenzó ya hace 20 años, con la introducción del registro electrónico federal para los recibos de almacén del algodón.

34. Otro ejemplo de sistema registral nacional para los documentos transmisibles electrónicos es la ley comercial de la República de Corea, que admite el conocimiento de embarque electrónico y establece la equivalencia legal entre los documentos en papel y los electrónicos, administrados por un registro de títulos electrónicos³⁵.

35. Por lo que respecta a la unicidad y singularidad, un segundo modelo es el sistema de símbolos (*tokens*); este símbolo es el equivalente electrónico de un documento original en papel. Hace mucho que se reconoce la posibilidad de que el símbolo (*token*) electrónico sea el equivalente de un documento original en papel. Así es que, por ejemplo, el artículo 17 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico reconoce la necesidad de contar con un original electrónico, pero no especifica la manera de proceder para lograrlo: simplemente exige que “se emplee un método fiable para garantizar la singularidad de ese mensaje o esos mensajes de datos”³⁶.

36. También el artículo 9 de las Reglas de Rotterdam establece la posibilidad de un documento transmisible electrónico que sea original y singular. Sin especificar la forma en que esto se puede lograr, las Reglas de Rotterdam dejan a discreción de las partes la elaboración de un procedimiento que cumpla con determinados requisitos en lugar de estipular un mecanismo determinado que deba aplicarse en todos los casos³⁷.

37. Por el contrario, si bien cuando el Grupo de Trabajo redactó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales reconoció la singularidad como un requisito de los documentos transmisibles electrónicos, también reconoció que encontrar una solución a ese problema requería una combinación de soluciones jurídicas, tecnológicas y comerciales que todavía no habían sido plenamente desarrolladas ni probadas. Por eso, como vimos anteriormente, esta Convención evitó la cuestión al excluir de su ámbito de aplicación los documentos transmisibles electrónicos³⁸.

un tercero es posiblemente la forma más eficaz de cumplir los requisitos [...] de que el documento [electrónico] transmisible siga siendo único, identificable e inalterable, al tiempo que ofrece la forma de garantizar que quede claramente anotado e identificado el beneficiario de la transmisión”.

³⁴ Véase el artículo 9-105 del Código Comercial Uniforme de los Estados Unidos.

³⁵ Véanse los párrs. 26 a 46 del documento A/CN.9/692.

³⁶ Véase el artículo 17 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la CNUDMI.

³⁷ Véase el artículo 9 de las Reglas de Rotterdam (“[e]l empleo de un documento electrónico de transporte negociable deberá observar ciertos procedimientos”).

³⁸ Véase el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales.

4. Posesión material y transmisión de derechos por tradición

38. Se han desarrollado modelos que están en funcionamiento para el equivalente funcional de la posesión física y la transmisión de derechos por tradición. Esto se logra con el concepto de “control” en la mayoría de los modelos jurídicos que regulan los documentos transmisibles electrónicos. Se considera que la persona que tiene el control del documento transmisible electrónico es el tenedor, que está facultado a ejercer los derechos establecidos en ese documento. Cuando el control de un documento transmisible electrónico sustituye a la posesión del documento de papel transferible, la transmisión del control sustituye a la tradición del documento. Según los modelos actuales el control también se puede lograr mediante los sistemas de símbolo (*token*) y de registro³⁹.

39. Según el modelo de símbolo (*token*), la identidad de la persona que ejerce el control del documento transmisible electrónico (el tenedor) figura en el documento propiamente dicho, y los cambios de titularidad (por ejemplo cesiones) se asientan modificando directamente el documento electrónico. Según este modelo, para determinar la identidad del titular del documento se requiere que el sistema mantenga una cuidadosa supervisión del documento electrónico en sí mismo, como así también del procedimiento de traspaso del control. Al igual que ocurre con el documento transferible en papel, puede ser necesario establecer garantías de seguridad o salvaguardias para garantizar la existencia de un único “ejemplar fehaciente”, que no pueda copiarse ni alterarse, y al que quepa remitirse para determinar la identidad del titular (así como lo estipulado en el documento transmisible electrónico propiamente dicho).

40. En el modelo registral la identidad del titular del documento transmisible electrónico se asienta en un registro independiente. Según este modelo establecer la titularidad del documento requiere control sobre el registro. El carácter original de un ejemplar del documento electrónico es aquí menos importante o relevante siempre que haya otra forma de verificar la integridad del documento transmisible electrónico asentado en el registro.

41. Este modelo ha demostrado ser un método eficaz y eficiente para obviar el requisito de la posesión física del documento en las operaciones electrónicas. Por ejemplo, en materia de valores bursátiles, reconociendo que en el mundo moderno no es práctico transmitir diariamente millones de acciones en papel de valores bursátiles, en 1992 los Estados Unidos introdujeron en su legislación el concepto de “control” para sustituir explícitamente la posesión material y la tradición de los

³⁹ Varios sistemas jurídicos que regulan los documentos transmisibles electrónicos han adoptado, o han adaptado, un modelo de registro. Un ejemplo en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos es el artículo 16 de la Ley Uniforme de operaciones electrónicas (relativo a los instrumentos electrónicos transmisibles) que establece sistemas registrales. En los comentarios oficiales se señala que “un sistema basado en un registro administrado por un tercero es posiblemente *la forma más eficaz* de cumplir los requisitos [...] de que el documento [electrónico] transmisible siga siendo único, identificable e inalterable, al tiempo que ofrece la forma de garantizar que quede claramente anotado e identificado el beneficiario de la transmisión”.

Otra ley nacional que ha adecuado un sistema registral es el artículo 862 de la Ley Comercial coreana revisada, promulgada el 3 de agosto de 2007 (Ley núm. 9746), que permite el uso del conocimiento de embarque electrónico. Establece la equivalencia legal entre un conocimiento de embarque consignado en papel y uno electrónico asentado en un registro de títulos electrónicos.

valores bursátiles⁴⁰. Y lo que es importante, el Convenio del Unidroit sobre el régimen sustantivo aplicable en materia de valores depositados en poder de un intermediario (Ginebra, 2009) prevé el reconocimiento de un “acuerdo de control”.

42. Ocurre lo mismo en los Estados Unidos, donde durante la última década la legislación que rige las operaciones garantizadas en el ámbito de la propiedad privada individual ha establecido el “control” sobre los activos intangibles que serían tangibles de no existir en formato electrónico⁴¹.

43. Por lo que se refiere específicamente a los documentos transmisibles electrónicos negociables, la legislación de los Estados Unidos ha extendido el concepto de control para abarcar tanto los títulos electrónicos transmisibles⁴² como los documentos transmisibles electrónicos⁴³. Otras leyes nacionales, como la ley comercial de la República de Corea, también prevén el “control” como una forma de posesión y transmisión de los documentos electrónicos de titularidad⁴⁴.

44. Las Reglas de Rotterdam también se basan en el control para cumplir con los requisitos de posesión y transmisión de los documentos transmisibles electrónicos⁴⁵. Vale decir que, además de los modelos nacionales vigentes, también hay un reconocimiento internacional de que la doctrina del “control” cumple con los elementos de posesión y de transmisión en el caso de los documentos transmisibles en las operaciones electrónicas. Si bien las Reglas de Rotterdam todavía no están en vigor y no aportan experiencia práctica en la materia, los ejemplos nacionales mencionados sí han demostrado ampliamente su utilidad.

5. Identificación y autenticación del tenedor

45. Cuando se emplea el control como sustituto de la posesión la parte que tiene el derecho de control queda automáticamente identificada, con lo cual ya no es necesario demostrar la identidad del tenedor, que antes se probaba con la posesión del título o documento. Para lograrlo se puede incorporar la prueba de la identidad de esa persona en el ejemplar autorizado, o se puede asociar ese ejemplar autorizado a un método que permita rastrear la identidad de esa persona, como por ejemplo un registro, de modo que quien consulte el ejemplar autorizado también quede alertado y tenga prueba del control. Por eso el concepto de “control” generalmente se define centrándose en la identidad de la persona facultada para ejercer los derechos establecidos en el documento transmisible electrónico.

⁴⁰ Código Comercial Uniforme de los Estados Unidos § 8-106.

⁴¹ Véase el artículo 9 del Código Comercial Uniforme: Operaciones garantizadas.

⁴² Véanse la Ley Uniforme de operaciones electrónicas, artículo 16 (documentos transmisibles) y la Ley de firmas electrónicas en el comercio global y nacional, artículo 201 (documentos transmisibles). Desde que se promulgó la Ley Uniforme de operaciones electrónicas se ha desarrollado en el país un amplio sector inmobiliario que prevé la utilización de la forma electrónica para el crédito hipotecario y los pagarés que lo acompañan, mediante el Mortgage Electronic Records System.

⁴³ El Código Uniforme Comercial, artículo 7-106 (control del documento de titularidad electrónico), artículo 7-501 b) (recibo de almacén y conocimiento de embarque, negociación y transmisión).

⁴⁴ Véase el artículo 862 de la Ley Comercial coreana reformada, promulgada el 3 de agosto de 2007 (Ley núm. 9746) (artículo que admite el conocimiento de embarque electrónico).

⁴⁵ Véanse los párrafos 21 y 22 del artículo 1, y los artículos 50 y 51 de las Reglas de Rotterdam.

V. Sectores que podrían beneficiarse de la labor en esta esfera

46. La labor de la CNUDMI en materia de documentos transmisibles electrónicos mejorará la práctica en los sectores que usualmente emplean este tipo de documento, y creará un entorno para que otros sectores puedan comenzar a utilizarlos. Más adelante se dan ejemplos de algunos de estos sectores. Es de esperar que en el curso de los debates del Grupo de Trabajo se puedan señalar otros sectores.

47. Debe tenerse en cuenta que lograr una mayor armonía y eficiencia en esta esfera del comercio puede dar un impulso a las economías en desarrollo tanto por adoptar una legislación moderna y eficiente en el comercio electrónico como por facilitar el comercio con la supresión de los obstáculos que representan las diferencias entre las leyes mercantiles de los socios comerciales.

A. Documentos de titularidad

48. En las economías agropecuarias los recibos de almacén electrónicos permitirán una mayor financiación garantizada por las mercancías almacenadas⁴⁶. La experiencia en los mercados agropecuarios nacionales donde se han utilizado estos recibos permite apreciar que algunas de ventajas de utilizar recibos electrónicos en lugar de recibos en papel son los menores costos de la transacción, la simplificación de la transmisión, la mayor seguridad para el tenedor y, en general, la mayor utilización de los recibos de almacén. Para los productores agropecuarios esto equivale a obtener beneficios notablemente mayores de la utilización de recibos de almacén, entre los que se encuentran un acceso más amplio al crédito, con montos mayores, la capacidad de responder a diferentes niveles de oferta y demanda provocados por las condiciones fluctuantes del mercado y la posibilidad de vender a granel y, por lo tanto, conseguir mayores réditos por el volumen. Los compradores también ganan al poder comprar a granel y regular la calidad de la mercancía. Todos estos beneficios destacan la importancia del recibo electrónico de almacén, especialmente en una economía agropecuaria en desarrollo, donde actualmente no son muy utilizados.

49. En el preámbulo de las Reglas de Rotterdam se expresa preocupación porque el actual régimen jurídico aplicable al transporte marítimo internacional de mercancías no tiene debidamente en cuenta las prácticas de transporte modernas, entre ellas la utilización de documentos electrónicos de transporte. Por lo tanto, en uno de sus capítulos (el capítulo 3) dedicado a los documentos electrónicos de transporte, se reconoce que las partes pueden utilizar conocimientos de embarque en papel o electrónicos. Este Grupo de Trabajo tal vez desee examinar normas aplicables al empleo de documentos electrónicos de transporte fuera del ámbito de las Reglas de Rotterdam, como así también normas que podrían reforzar las disposiciones pertinentes de las Reglas de Rotterdam.

B. Títulos

⁴⁶ Henry Gabriel, "Warehouse Receipts and Securitization in Agricultural Finance" 17 Uniform Law Review 369 (2012).

50. Los documentos transmisibles electrónicos se están utilizando actualmente en operaciones financieras que dependen de la postergación del pago o del descuento de créditos, como por ejemplo las líneas de crédito que ofrecen los bancos⁴⁷. Generalmente se emite un título negociable (como por ejemplo un pagaré); sin embargo, a veces se evita el uso de un título negociable por el peso administrativo que representa el procesamiento del papel requerido para estas operaciones. En su lugar las entidades recurren al simple “descuento de facturas” o “cuentas por cobrar”, que consisten en una mera cesión de crédito. Con la facultad de emitir títulos electrónicos negociables válidos se darán condiciones más seguras para la transferencia de créditos y mecanismos más eficaces para la reclamación de pagos que dependen de formas exentas de las trabas que presenta la forma escrita⁴⁸.

51. La emisión y transmisión electrónica de documentos negociables también tendrá consecuencias para los servicios u operaciones que dependen del uso de créditos personales o de títulos negociables como garantía. En general, todos los servicios u operaciones que implican la postergación del pago como una forma de financiación para el deudor se benefician con la posibilidad de transmitir derechos en forma electrónica.

52. Los documentos transmisibles electrónicos también serán una ventaja para el crédito hipotecario⁴⁹. El deudor hipotecario emite pagarés electrónicos que se reúnen en un conjunto de documentos electrónicos que se relacionan con el préstamo. La seguridad que aporta el hecho de que para el pago se utilicen títulos negociables hace posible, entre otras cosas, la adquisición del préstamo por intermediarios y su reventa en el mercado secundario⁵⁰. Los sistemas actualmente vigentes emplean registros que son controlados por las instituciones adquirentes o intermediarias mediante auditorías y acreditaciones. El régimen sustantivo en este sistema electrónico es esencialmente el mismo que el aplicable a los títulos en papel. Lo mismo ocurre con muchas instituciones de educación, que ofrecen la posibilidad de financiar las tasas universitarias mediante pagarés emitidos en forma electrónica⁵¹. Es importante tener en cuenta que los documentos

⁴⁷ Como una forma de financiación del comercio los bancos suelen descontar los créditos comerciales. Esta estructura también se utiliza en los servicios de factoraje. Este tipo de servicios suele requerir la presentación de facturas o de otro documento que pruebe la transacción que da origen al crédito.

⁴⁸ En una encuesta realizada entre las entidades bancarias españolas (en la que figuraban la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros) el 100% de quienes respondieron afirmaron que brindaban servicios financieros basados en el empleo de instrumentos negociables. El 83% de ellos afirmó que dichos servicios eran “muy frecuentes” (el otro 17% los calificó como “usuales”). Además, el 100% afirmó que brindaban servicios de descuento de créditos (o que implicaban la utilización de créditos como garantía) que no recurrían a la emisión o transmisión de documentos negociables. El 66% de ellos afirmó que lo hacían debido a los inconvenientes derivados de la necesidad de depender de un papel para el ejercicio o la transmisión de derechos. Todos afirmaron que habían encontrado o que encontrarían beneficios de una legislación que regulara expresamente el uso de títulos electrónicos negociables o la transmisión electrónica de derechos con resultados o condiciones equivalentes.

⁴⁹ Véase la nota 42 *supra* que menciona la experiencia pertinente en los Estados Unidos.

⁵⁰ Como se afirmó en una sección anterior, esto se hace mediante el Mortgage Electronic Registration System regido por el marco jurídico establecido por los Estados Unidos.

⁵¹ La oficina federal de ayuda al estudiante, del Ministerio de Educación de los Estados Unidos, administra un programa para financiar los gastos y las tasas de educación que depende de la

transmisibles electrónicos no se comenzaron a utilizar en los créditos hipotecarios hasta que no hubo un marco jurídico que los regulara. También se debe tener en cuenta que ese mismo tipo de documentos puede servir de base para el desarrollo de nuevos modos de financiación todavía no imaginados.

53. Otros sectores también se pueden beneficiar de los documentos transmisibles electrónicos y de la transmisión electrónica de derechos. El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar las empresas cuyos servicios en alguna medida dependen de la transmisión de documentos o derechos. Por ejemplo, las operaciones que implican una garantía independiente o una carta de crédito también se benefician de la utilización de documentos transmisibles.

utilización de pagarés.

**D. Nota de la Secretaría — Panorama general de la gestión de la
identidad — Documento de antecedentes presentado
por el *Identity Management Legal Task Force de la American
Bar Association*, presentada al Grupo de Trabajo sobre
Comercio Electrónico en su 46º período de sesiones
(A/CN.9/WG.IV/WP.120)**

[Original: inglés]

En el marco de la preparación del 46º período de sesiones del Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico), el equipo de tareas *Identity Management Legal Task Force* de la *American Bar Association* ha presentado a la Secretaría el documento adjunto.

El documento es traducción de un texto que fue reproducido en la forma en que lo recibió la Secretaría.

I. Introducción

1. En 2011, en un informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) se señalaba que la gestión de la identidad digital es fundamental para el desarrollo ulterior de la economía de la Internet¹ y es requisito esencial de todas las formas de comercio electrónico.
2. El presente documento ofrece una visión general de la gestión de la identidad digital, su función en el comercio electrónico, las cuestiones jurídicas que plantea y las barreras legales que plantea². Se basa en la labor que adelanta el grupo de tareas *Identity Management Legal Task Force de la American Bar Association* (ABA)³, y se presenta como material de antecedentes para informar al Grupo de Trabajo de cuestiones pertinentes⁴.
3. En su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión convino en volver a reunir al Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) para que se ocupara

¹ OECD (2011) "Digital Identity Management for Natural Persons: Enabling Innovation and Trust in the Internet Economy - Guidance for Government Policy Makers," *OECD Digital Economy Papers*, núm. 196, OECD Publishing, pág. 3; el texto se puede consultar en www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/digital-identity-management-for-natural-persons_5kg1zqsm3pns-en.

² El presente documento se centra en los sistemas de gestión de la identidad comerciales concebidos para su utilización en el contexto empresarial, en particular en las comunicaciones entre empresas, entre empresas y gobiernos y entre empresas y consumidores.

³ Identity Management Legal Task Force, Cyberspace Law Committee, American Bar Association, Section of Business Law; <http://apps.americanbar.org/dch/committee.cfm?com=CL320041>. Las opiniones expresadas en el presente documento no han recibido la aprobación de la comisión de delegados o la junta de gobernadores de la *American Bar Association* y, en consecuencia, no se deben interpretar como representación de la política de la ABA.

⁴ Se puede consultar asimismo material adicional en la documentación del Coloquio de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, celebrado en Nueva York del 14 al 16 de febrero de 2011, disponible en www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/electronic-commerce-2010.html.

del tema de los documentos transmisibles electrónicos⁵. Al mismo tiempo, la Comisión convino en la ampliación del mandato del Grupo de Trabajo para que abarcara, por separado y no en relación con los documentos transmisibles electrónicos, temas tratados en los documentos A/CN.9/728 y Add.1⁶. Esos temas comprendían la gestión de la identidad, la ventanilla única y los pagos mediante dispositivos móviles⁷.

4. Como se señala más adelante (párrs. 6 y 7), la gestión de la identidad digital es un requisito fundamental respecto de cada uno de los temas pertinentes que la Comisión examinó en su 44º período de sesiones (documentos transmisibles electrónicos, ventanilla única y pagos mediante dispositivos móviles). Por ello, será también un tema importante para la labor en curso del Grupo de Trabajo relacionada con los documentos transmisibles electrónicos y para cualquier posible labor futura relacionada con los demás temas.

5. Es bien reconocida la importancia decisiva de la gestión de la identidad digital para facilitar el comercio electrónico fiable. Numerosos grupos intergubernamentales, estados, grupos internacionales privados y entidades comerciales estudian activamente las cuestiones y oportunidades relacionadas con la gestión de la identidad, elaboran normas técnicas y procesos empresariales y buscan formas de aplicar sistemas de identidad digital viables. A título de ejemplo, cabe mencionar:

a) Los Grupos intergubernamentales que trabajan activamente en cuestiones y normas de gestión de la identidad digital, entre los que figuran la OCDE⁸, la Organización Internacional de Normalización (ISO)⁹ y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)¹⁰;

b) En un estudio emprendido por la OCDE¹¹ se identificaron 18 países de esa Organización que adelantan activamente estrategias nacionales relacionadas con la gestión de la identidad (Alemania, Australia, Austria, Canadá, Chile, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, República de Corea, Suecia y Turquía)¹². Otros varios países, como Estonia, la India y Nigeria, también aplican activamente estrategias de esa índole;

c) Varios proyectos regionales relacionados con la identidad digital se encuentran en marcha en la Unión Europea, entre los que cabe mencionar PrimeLife (un proyecto del Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea)¹³, Global Identity Networking of Individuals - Support Action (GINI-SA)¹⁴, STORK

⁵ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17)*, párr. 250.

⁶ *Ibid.*, párr. 251.

⁷ *Ibid.*, párr. 241 a 249.

⁸ www.oecd.org/document/38/0,3746,en_2649_34255_49319782_1_1_1_1,00.html.

⁹ www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=45306.

¹⁰ www.itu.int/ITU-T/studygroups/com17/fgidm.

¹¹ Bernat, L. (2011), "National Strategies and Policies for Digital Identity Management in OECD Countries", OECD Digital Economy Papers, No. 177, OECD Publishing. doi: 10.1787/5kgdzvn5rfs2-en; at www.oecd-ilibrary.org/content/workingpaper/5kgdzvn5rfs2-en.

¹² *Ibid.*, en las págs. 28 a 35 figura una lista de enlaces a documentos de los países.

¹³ www.primelife.eu.

¹⁴ www.gini-sa.eu.

(encaminado a establecer una plataforma europea de interoperabilidad de la eID)¹⁵, y la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA)¹⁶;

d) Entre las organizaciones privadas que trabajan en normas y políticas de identidad digital a nivel internacional figuran la Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)¹⁷, la Open Identity Exchange (OIX)¹⁸, la Iniciativa Kantara¹⁹, la Open ID Foundation²⁰, tScheme²¹ y la Internet Society²²;

e) Se han establecido algunos sistemas de identidad digital comerciales que funcionan a escala mundial en esferas reducidas. Entre ellos figuran los que administran Transglobal Secure Collaboration Program (TSCP)²³ y CertiPath²⁴ para las industrias aeroespacial y de defensa, la SAFE-BioPharma Association²⁵ para la industria biofarmacéutica, IdemTrust²⁶ para el sector financiero, el CA/Browser Forum²⁷ para los certificados EV-SSL de sitios web y FiXs - Federation for Identity and Cross-Credentialing Systems (FiXs)²⁸. La labor de esos grupos se centra primordialmente en cuestiones relacionadas con normas técnicas y procesos empresariales y no en cuestiones de orden jurídico.

II. Relación entre la gestión de la identidad digital y el comercio electrónico

6. La gestión de la identidad digital es una cuestión fundamental para la mayoría de las transacciones del comercio electrónico y otras actividades en línea. Una preocupación primordial es la verificación de la identidad de partes alejadas que tratan, por ejemplo, de acceder a una base de datos en línea que contienen información confidencial, para realizar una transferencia en línea de fondos con cargo a una cuenta, o que han firmado un contrato electrónico, autorizado a distancia el despacho de un producto o enviado un correo electrónico. Si bien los participantes en muchas transacciones de bajo riesgo realizadas en línea tienden a confiar en que están tratando con una persona o entidad concreta, a medida que aumenta la confidencialidad o el valor de la transacción aumenta también la importancia de garantizar la disponibilidad y fiabilidad de información exacta acerca de la identidad de la parte que se encuentra a distancia a fin de tomar una decisión fundada en la confianza.

¹⁵ www.eid-stork.eu.

¹⁶ www.enisa.europa.eu.

¹⁷ www.oasis-open.org/home/index.php.

¹⁸ www.openidentityexchange.com.

¹⁹ <http://kantarainitiative.org>, conocida anteriormente como la Liberty Alliance, www.projectliberty.org.

²⁰ <http://openid.net/foundation>.

²¹ www.tscheme.org.

²² www.internetsociety.org.

²³ www.tscp.org.

²⁴ www.certipath.com.

²⁵ www.safe-biopharma.org.

²⁶ www.identrust.com.

²⁷ www.cabforum.org.

²⁸ www.fixs.org.

7. La gestión de la identidad digital es un requisito básico en lo tocante a las firmas electrónicas, al tema de los documentos transmisibles electrónicos y a cualquier posible labor futura relacionada con los demás temas (ventanilla única y pagos mediante dispositivos móviles)²⁹.

a) La determinación de la identidad del signatario es uno de los requisitos para crear una firma electrónica válida. Tanto el artículo 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (1996) como el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (2005, Convención sobre Comunicaciones Electrónicas) estipulan, como condición de una firma electrónica válida, que se utilice para identificar al signatario un método que sea tan viable como sea apropiado para los fines para los que se generó o comunicó el mensaje de datos. El artículo 2 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas requiere también como componente de una firma electrónica datos “que puedan ser utilizados para identificar al firmante”;

b) La verificación de la identidad es también un requisito decisivo de los documentos transmisibles electrónicos, la ventanilla única y los pagos mediante dispositivos móviles. Las leyes vigentes relativas a los documentos transmisibles electrónicos requieren que se determine la identidad tanto del firmante del documento como de la persona habilitada para hacer valer los derechos incorporados en él³⁰. Los procesos de ventanilla única requerirán la determinación de la identidad del firmante de los documentos de aduana y la identidad de la persona o entidad que los archiva y la persona o entidad habilitada para hacerlos efectivos³¹. Asimismo, los pagos mediante dispositivos móviles, al igual que todos los demás sistemas de pago, requieren (a efecto de autorización) la identidad de la persona que afirme que transfiere los fondos³².

III. Definición de la gestión de la identidad digital

8. Esencialmente, la gestión de la identidad digital tiene por objeto responder a dos preguntas sencillas que cada una de las partes en una transacción en línea se formula acerca de la otra parte, a saber, “¿quién es usted?” y “¿cómo puede demostrarlo?”. La capacidad para dar una respuesta fiable y creíble a esas preguntas se ha venido convirtiendo rápidamente en un requisito decisivo de las actividades del comercio electrónico, especialmente a medida que aumenta la índole, la importancia y la confidencialidad de ese tipo de transacciones. Apoyándose en las respuestas a esas dos preguntas, la parte en una transacción en línea puede decidir si procede o no a efectuar la transacción (por ejemplo, si celebra un contrato con la otra parte, si permite a la otra parte el acceso a una base de datos confidencial o si otorga a la otra parte algún otro privilegio o tipo de acceso).

9. Si bien toda entidad que sea parte en transacciones digitales podría crear su propio sistema para identificar a cada una de sus contrapartes comerciales y

²⁹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17)*, párrs. 241 a 252.

³⁰ A/CN.9/WG.IV/WP.115, párrs. 24 a 26 y 45 a 48.

³¹ A/CN.9/728/Add.1, párrs. 42 y 45.

³² Véase, A/CN.9/728, parr. 52.

autenticar su identidad (como lo hacen actualmente muchas empresas mediante la utilización de distintos procesos de registro, unidos a un sistema de nombre de usuario y contraseña), esa modalidad está demostrando ser cada vez más costosa e inadecuada y plantea el problema de adaptar el sistema a poblaciones más amplias. Además, la creciente necesidad de la colaboración interinstitucional, las preocupaciones de seguridad y el problema de la administración de las contraseñas de los usuarios indican que ya no es adecuado el método habitual de nombres de usuario y contraseñas asignados por una empresa o por un proveedor.

10. En consecuencia, están surgiendo como método preferido los sistemas de identidad digital en los que el proveedor de la identidad de terceros (o proveedor de atributos) cumple una función básica. El objetivo es permitir que las empresas y los organismos gubernamentales realicen transacciones electrónicas con partes distantes apoyándose en la información sobre la identidad y los procesos de autenticación que ofrezca cualquiera de los varios proveedores independientes de identidad de terceros. Esa modalidad se denomina a menudo sistema de identidad “federado”. En otras palabras, la información sobre la identidad verificada por una entidad se facilita de manera convenida y controlada a múltiples partes en el marco de diferentes sistemas que tengan necesidad de información sobre la identidad con diversos propósitos. Ello permitiría, por ejemplo, que los particulares y las empresas utilizaran una credencial de identidad de su elección para realizar transacciones en línea con numerosas empresas, de la misma manera que una persona podría utilizar una licencia de conducir para una diversidad de transacciones diferentes de tipo no electrónico con diferentes entidades, como la compra de alcohol, la admisión a la zona de embarque de un aeropuerto o la apertura de una cuenta bancaria.

11. El desarrollo de un sistema de identidad federado requiere una combinación de normas y sistemas técnicos³³, procesos y procedimientos empresariales y normas jurídicas que, tomados en conjunto, creen un sistema fiable a fin de: i) verificar la identidad y vincular esa identidad con una persona física, entidad jurídica, dispositivo u objeto digital; ii) suministrar esa información sobre la identidad a una parte que la requiera para autorizar una transacción; y iii) mantener y proteger esa información durante su ciclo de duración. Un elemento fundamental para hacer que ese sistema funcione en un contexto comercial es el requisito de un marco jurídico idóneo y, típicamente, basado en un contrato que defina los derechos y responsabilidades de las partes, distribuya los riesgos y sirva de base para su aplicación. Ese marco jurídico se conoce a menudo como “reglas de funcionamiento” o “marco de confianza”.

IV. Consideraciones básicas sobre la gestión de la identidad

12. Aunque la expresión “gestión de la identidad” es relativamente nueva, el concepto no lo es. Los procesos en que se apoya se han venido utilizando por largo tiempo en entornos fuera de línea. Los pasaportes, las licencias de conducir y las tarjetas de identificación de empleados son todos componentes de sistemas de identidad (en otras palabras, son credenciales expedidas por una entidad a personas

³³ Uno de los métodos que podría utilizarse para establecer un sistema de identidad es la infraestructura de clave pública (ICP). Sin embargo, se están desarrollando y aplicando muchas otras tecnologías y métodos.

cuya identidad ha confirmado de modo que posteriormente puedan demostrarla). El proceso de identificación de una persona y expedición de la correspondiente credencial también lo puede efectuar la parte que acepta la credencial (como ocurre con las tarjetas de identificación de empleados expedidas por una empresa) o un tercero (como ocurre con las licencias de conducir o el pasaporte). Un elemento básico de los sistemas federados, en los que hay un tercero que expide la credencial, es que el empleo de esas credenciales de identidad no está restringido a transacciones con las entidades que las expiden. Por el contrario, han sido concebidos y se utilizan previendo que las credenciales serán aceptadas por terceros (por ejemplo, el personal de seguridad de un aeropuerto, un banco o un barman en el caso de las licencias de conducir) cuando se exige prueba de determinados atributos de la propia identidad (como el nombre o la edad).

13. El problema se plantea a la hora de implantar una capacidad similar en un contexto en línea, o sea, crear un sistema de credenciales de identidad digital seguro, fiable y fehaciente que se puedan utilizar a distancia en el marco de sistemas y entidades diferentes (o sea, crear un sistema de identidad federado). Ese sistema permitirá a los sujetos a los que corresponden los datos utilizar la misma credencial de identidad para identificarse a fin de poder acceder a recursos o realizar transacciones con múltiples organizaciones.

14. Si bien hay muchos enfoques diferentes de la gestión de la identidad, esta entraña esencialmente dos procesos fundamentales: i) el proceso de reunir y verificar determinados atributos de identidad que corresponden a una persona (o a una entidad, dispositivo u objeto digital)³⁴ y expedir una credencial de identidad que refleje esas características (“identificación”) y ii) el proceso de verificar posteriormente que una persona determinada que presenta esa credencial y sostiene que es la persona previamente identificada es, de hecho, esa persona (“autenticación”). Cada uno de esos procesos básicos puede entrañar diversos subprocesos, según la naturaleza de los datos y el contexto en que tienen lugar los dos procesos. Una vez que se han autenticado positivamente los atributos de identidad de una persona, viene un tercer grupo de procesos, conocidos en conjunto como “autorización”, que están a cargo de la entidad que se propone apoyarse en la identidad autenticada para determinar los derechos y privilegios que se concederán a esa persona (por ejemplo, si se celebra un contrato con ella o si se le debe conceder acceso a una base de datos o una cuenta bancaria en línea).

A. Identificación

15. La finalidad del proceso de identificación es responder a la pregunta “¿quién es usted?”. Ese proceso, que realiza alguien que cumple la función de proveedor de identidad³⁵, entraña la vinculación de los atributos identificantes (como nombre, número de afiliación, dirección o fecha de nacimiento) con una persona determinada, a fin de identificarla y definirla al nivel adecuado para el propósito

³⁴ La información acerca de la identidad se puede reunir y verificar (y se pueden emitir las correspondientes credenciales de identidad) respecto de particulares, entidades jurídicas, dispositivos y objetos digitales. El presente documento se centra únicamente en los sistemas de identidad relacionados con personas físicas.

³⁵ En algún caso, cuando solo se requieran atributos seleccionados para el proceso de identificación, una entidad conocida como proveedor de atributos cumple esa función.

previsto. Llamado a veces “comprobación de la identidad” o “inscripción”, ese proceso a menudo se lleva a cabo una sola vez. Un proveedor de identidad suele reunir información acerca de la persona que ha de ser identificada (denominada el “sujeto”) y se apoya con frecuencia en una diversidad de documentos emitidos oficialmente (por ejemplo, partida de nacimiento, tarjeta de la seguridad social, licencia de conducir y pasaporte) y en credenciales expedidas por entidades del sector privado (por ejemplo, distintivo de identificación de empleado, tarjeta SIM de comunicación inalámbrica por móvil y tarjetas de crédito). Aunque esos documentos y credenciales de identidad hayan sido expedidos con otros fines, con frecuencia se pueden volver a utilizar para facilitar más adelante procesos de identificación en nuevos contextos. Así ocurre, por ejemplo, cuando alguien presenta una licencia de conducir para demostrar su identidad a la hora de recibir un distintivo de identificación de empleado.

16. Al final del proceso de identificación, los atributos de identidad pertinentes del sujeto suelen quedar recogidos en datos consignados en un documento electrónico expedido por el proveedor de la identidad y que se conoce como credencial de identidad. La credencial presenta (o vincula o correlaciona) los datos que se utilizan para autenticar la identidad digital invocada o los atributos de una persona, entidad o dispositivo³⁶. Una credencial puede ser incorporada en una diversidad de medios. En el mundo físico, son ejemplos de una credencial de identidad el sello real, la licencia de conducir, el pasaporte, la tarjeta de una biblioteca o el distintivo de identificación de empleado. En el mundo en línea, la credencial de identidad puede ser tan sencilla como la identificación de usuario o tan compleja como un certificado digital expresado criptográficamente que puede ser almacenado en una computadora, un teléfono móvil, una tarjeta inteligente, una tarjeta de cajero automático, una memoria informática o cualquier dispositivo similar.

B. Autenticación

17. Cuando una persona presenta una credencial (por ejemplo, una licencia de conducir en un aeropuerto o al registrar la identificación de usuario en una red de empresas) declara que es la persona identificada en la credencial y pide ejercitar un derecho o privilegio otorgado a esa persona (por ejemplo, abordar un avión, acceder a una red corporativa o a una base de datos confidencial), la “parte receptora” recurre a un proceso de autenticación para determinar si esa persona es, de hecho, quien afirma ser. En otras palabras, una vez que alguien declara quién es (afirmando ser la persona identificada en la credencial de identidad), la autenticación tiene por objeto responder a la pregunta “muy bien, ¿cómo puede probarlo?”. Se trata de un trámite relacionado con una transacción concreta que supone la vinculación de la persona con la credencial de identidad presentada, a fin de verificar que la persona que desea intervenir en la transacción es realmente la que ha sido identificada mediante la credencial.

18. La autenticación suele requerir un elemento que vincule a la persona con la credencial, elemento que se conoce por lo general como autenticador. Cuando la credencial es una licencia de conducir o un pasaporte, el autenticador es la

³⁶ OECD Guidance for Electronic Authentication (2007), pág. 12, se puede consultar en www.oecd.org/dataoecd/32/45/38921342.pdf.

fotografía y la vinculación se hace de ordinario comparando la fotografía que se encuentra en la licencia o el pasaporte con la persona que los presente. En el caso de las credenciales electrónicas, el autenticador es normalmente un dato que la persona “conoce” (por ejemplo, una contraseña secreta o un número de identificación personal), una información que la persona “posee” (por ejemplo, una clave criptográfica privada, un dispositivo físico como una tarjeta inteligente, un USB u otro tipo de señal) o algo que la persona “es”, por ejemplo, una característica física (comprobada en una fotografía, las huellas digitales u otros datos biométricos).

C. Autorización

19. Una vez hecha la autenticación debida de una persona, la parte receptora puede emplear su propio proceso de autorización para determinar los derechos y privilegios que se otorgan a esa persona (por ejemplo, si se le debe dar acceso a un sitio web, una base de datos, un bar o la zona de embarque de un aeropuerto). Ese proceso plantea la pregunta “¿A qué está usted autorizado?”. Por ello, la autenticación de la identidad no constituye solamente un fin en sí. Con frecuencia se emplea para facilitar las decisiones de autorización de la parte receptora como la concesión de derechos o privilegios (por ejemplo, el acceso a los recursos en línea del sistema) o para celebrar una transacción. Por ejemplo, una vez que la identidad de una persona que solicita acceso a una red informática ha sido autenticada, el propietario del sistema (o sea, la parte receptora) puede emplear un proceso de autorización a fin de determinar los derechos de acceso que se le deberían conceder. Asimismo, una vez autenticada la identidad de alguien que desee celebrar una transacción electrónica (por ejemplo, un contrato electrónico), la parte receptora puede utilizar un proceso de autorización para determinar si procede a realizar la transacción con el interesado o utiliza de alguna otra forma la comunicación.

D. Identidad federada

20. Tratándose de transacciones en línea, comúnmente la identificación y la expedición de credenciales las ha efectuado la misma parte que tiene también la intención de exigir la credencial. Por ejemplo, una empresa identificará a un empleado y le asignará un nombre de usuario y una contraseña que le permita acceder a la red de la empresa. En tal caso, esta actúa tanto como proveedor de la identidad (ya que ha identificado la persona como su empleado y le ha expedido una credencial de identidad) y como parte receptora (puesto que también acepta y se sirve de esa credencial para autorizar el acceso a su red).

21. En un sistema de identidad “federado”, las funciones de proveedor de la identidad y parte receptora no las cumple necesariamente la misma entidad. Por el contrario, múltiples partes receptoras no relacionadas entre sí pueden aceptar las credenciales de identidad que expida cualquiera de los diversos proveedores de identidad independientes. De acuerdo con ese modelo, una única credencial de identidad puede ser aceptada por numerosas organizaciones que no hayan tenido participación directa en la expedición original de la credencial.

22. En los servicios fuera de línea, un ejemplo conocido de un proceso federado de gestión de la identidad es la forma en que actualmente se expiden y utilizan las

licencias de conducir. Esas licencias, expedidas por una entidad gubernamental, las utilizan diversas partes receptoras no relacionadas entre sí para verificar los atributos de identidad del titular de la licencia. Por ejemplo, un agente de seguridad la utiliza para comprobar el nombre de una persona que solicita ingresar a la zona de embarque de un aeropuerto o un barman para verificar la edad de la persona que pide una bebida alcohólica.

23. En los servicios en línea de sistema de identidad federado, un ejemplo es el de los cajeros automáticos. En una transacción típica en un cajero automático una persona que tenga una cuenta en el banco A puede utilizar la credencial de identidad que le ha expedido su propio banco (la tarjeta de cajero) para retirar dinero en efectivo en un cajero operado por el banco B (con el que el interesado no tiene ninguna vinculación). Para dar curso a la transacción, a pesar de que no exista una vinculación de esa índole, el banco B se pone en contacto con el banco A a través de la red de cajeros automáticos para determinar si la persona es un cliente autorizado del banco A, hacer que el banco A autentique la identidad del cliente (o sea, determine si utilizó la contraseña correcta) y para obtener de ese banco determinada información sobre la identidad relacionada con el cliente (por ejemplo, si en la cuenta hay fondos suficientes que respalden el retiro de dinero solicitado y, en algunos casos, obtener el saldo de la cuenta a fin de que el banco B lo pueda imprimir en el recibo de la transacción).

IV. Riesgos de los sistemas de identidad

24. La participación en un sistema de identidad y el recurso a los datos correspondientes entraña varios riesgos posibles, entre los que figuran:

a) Riesgo en la identificación: la fiabilidad de la información reunida y declarada sobre la identidad de los sujetos es de importancia decisiva para la utilización de cualquier sistema de identidad. El riesgo en la identificación representa el riesgo de que los datos sobre los atributos de la identidad reunidos y vinculados a un sujeto determinado sean inexactos. Ese riesgo está a menudo en relación directa con la calidad de las credenciales de identidad en contextos fuera de línea suministradas por el sujeto para la verificación de su identidad;

b) Riesgo en la autenticación: la identificación no tiene utilidad a menos que la parte receptora tenga la capacidad de autenticarla (o sea, de vincular los atributos de identidad declarados con el sujeto correcto). El riesgo en la autenticación incluye tanto el riesgo de que un sujeto legítimo no pueda ser adecuadamente objeto de autenticación como el riesgo de que el proceso de autenticación indique incorrectamente que un impostor es el sujeto legítimo;

c) Riesgo relacionado con la privacidad: en el caso de los particulares la gestión de la identidad conlleva la reunión y verificación de información personal acerca de un sujeto por parte de un proveedor de identidad y el intercambio de esa información con múltiples partes receptoras. Además, las transacciones basadas en la identidad pueden facilitar también el rastreo de las actividades de una persona, con lo cual se genera información personal adicional. El riesgo relacionado con la privacidad tiene que ver principalmente con la utilización no autorizada o el abuso de la información personal acerca del sujeto por una de las partes que tiene acceso a

ella y con el cumplimiento por esas entidades de las obligaciones tocantes a la elaboración y protección de los datos;

d) Riesgo relacionado con la seguridad de los datos: en cualquier sistema de identidad es de importancia decisiva la protección de la información personal acerca de los sujetos identificados y el mantenimiento de la seguridad de los procesos necesarios para crear credenciales de identidad seguras, comunicar información exacta sobre la identidad, verificar la situación de las credenciales de identidad y autenticar a los sujetos. El riesgo de seguridad comprende el peligro de que una parte no autorizada pueda obtener acceso a datos personales y el riesgo de que se vea comprometido cualquiera de los procesos fundamentales para el funcionamiento general del sistema de identidad o cualquiera de las distintas transacciones relacionadas con la identidad;

e) Riesgo relacionado con la responsabilidad: en todo sistema de identidad ocurrirán inevitablemente fallos y se ocasionarán perjuicios. Los participantes en un sistema de identidad deben enfrentarse al riesgo de que se les haga responsables de perjuicios sufridos por un tercero como resultado de un problema que hayan ocasionado o del que se les considere jurídicamente responsables. Un aspecto básico del riesgo de responsabilidad es la incertidumbre jurídica respecto de la responsabilidad inherente a un acto u omisión determinados por parte de un participante en un sistema de identidad, en particular cuando opera en múltiples sectores empresariales y jurisdiccionales;

f) Riesgo relacionado con la ejecutoriedad: el riesgo relacionado con la ejecutoriedad es complementario del riesgo de responsabilidad. Se trata del riesgo de que un participante no pueda hacer valer i) su derecho a que otro participante cumpla con las normas, o ii) su derecho a recibir indemnización por daños y perjuicios cuando sufra efectivamente daños en caso de que otro participante sea jurídicamente “responsable”. Este riesgo se da cuando algo sale mal y alguien trata de reclamar indemnización por daños y perjuicios. Se aplica también en situaciones en que aunque un problema no haya surgido todavía, un error de ejecución por parte de uno o más participantes puede poner en peligro la totalidad del sistema de identidad. Ese aspecto es particularmente importante en un sistema multijurisdiccional. En tal caso, el riesgo relacionado con la ejecutoriedad se refiere tanto a la capacidad de detectar el problema como a la capacidad de exigir que el participante subsane su error de ejecución o se retire del sistema;

g) Riesgo relacionado con el cumplimiento reglamentario: en muchos casos, la participación en un sistema de identidad plantea cuestiones de cumplimiento jurídico para uno o más de los participantes (o sea, determinar si la conducta del participante cumple con las leyes nacionales aplicables). En otros casos, el propósito de la participación en el sistema de identidad es, por su propia índole, un esfuerzo por cumplir los requisitos legales impuestos a un participante. Por ejemplo, una institución financiera puede participar en el sistema y apoyarse en las credenciales de identidad con miras a satisfacer sus obligaciones jurídicas de autenticar debidamente a las personas a las que concede acceso en línea a cuentas bancarias y servicios de pago. En tales casos, el riesgo relacionado con el cumplimiento tiene que ver principalmente con la determinación de si esa participación satisface las obligaciones jurídicas.

25. Como ocurre con cualquier sistema, los riesgos anteriormente descritos dependen de la tecnología utilizada, de los diversos procesos ejecutados y de la forma en que los propios participantes cumplen o dejan de cumplir las obligaciones (así como de la posible influencia de partes externas). La creación de un sistema de identidad fiable exigirá medidas para abordar esos riesgos, o sea, medidas para garantizar que los participantes pueden confiar en la tecnología empleada (garantizar que funciona adecuadamente), en los procesos aplicados (garantizar que producen el resultado correcto) y en otros participantes (garantizar que habrán de cumplir debidamente sus obligaciones).

V. Relación entre funcionalidad y riesgo: reglas de funcionamiento

26. Para lograr que un sistema de identidad federado funcione en un entorno en línea y abordar riesgos como los arriba indicados se requiere no solo la aplicación de una tecnología apropiada, sino también el cumplimiento por todos los participantes (sujetos, proveedores de identidad y partes receptoras) de un cuerpo común de normas técnicas, requisitos operacionales y reglas jurídicas. Los sistemas de identidad comerciales suelen tratar de lograr ese objetivo mediante la formulación de “reglas de funcionamiento” apropiadas (que a veces se conocen como “marco de confianza”) a cuyo cumplimiento los participantes están contractualmente obligados.

27. Las reglas de funcionamiento de los sistemas de identidad se agrupan en dos categorías generales de componentes, a saber: i) las reglas operacionales y especificaciones técnicas y empresariales necesarias para hacer que el sistema sea funcional y fiable y ii) las normas jurídicas de tipo contractual que, además de las leyes y reglamentos aplicables, definen los derechos y obligaciones jurídicas de las partes que sean específicos del sistema de identidad y faciliten cuando sea necesario su cumplimiento.

a) Las reglas operacionales técnicas y empresariales definen los requisitos de funcionamiento adecuado del sistema de identidad y las funciones y responsabilidades operacionales de los participantes, y ofrecen una garantía adecuada de la exactitud, integridad, privacidad y seguridad de sus procesos y datos (de modo que las diversas partes se muestren dispuestas a participar y que el sistema merezca confianza). En muchos casos esas reglas se basan en normas ya existentes;

b) Las normas jurídicas de tipo contractual corresponden a acuerdos celebrados entre los participantes sobre la base de un contrato que definen y regulan los derechos, responsabilidades y obligaciones jurídicas de los participantes con respecto al sistema de identidad de que se trate, clarifican los riesgos jurídicos que las partes asumen por el hecho de participar en el sistema de identidad (por ejemplo, garantías, responsabilidad por daños, riesgos para sus datos personales); y prevén recursos en caso de que surjan diferencias entre las partes, entre ellos métodos de solución de controversias, mecanismos de ejecución, derechos de rescisión y medidas de indemnización por daños y perjuicios, sanciones y otras formas de responsabilidad. En virtud de esas normas las reglas operacionales técnicas y empresariales adquieren carácter jurídico vinculante para los participantes y tienen fuerza legal frente a ellos.

28. Tanto las normas operacionales técnicas y empresariales como las reglas jurídicas de base contractual están, desde luego, sujetas a otros deberes y obligaciones existentes derivados del derecho estatutario y reglamentario que se aplique a las partes, y se suelen interpretar con referencia a ellos. Los dos componentes de las normas operativas del sistema de identidad (o sea, las normas operacionales técnicas y empresariales y las normas jurídicas) están sujetos a los estatutos y reglamentaciones vigentes que se apliquen en la jurisdicción o jurisdicciones pertinentes y en las que el sistema de identidad habrá de funcionar o se habrá de utilizar.

29. Las normas de funcionamiento de los sistemas de identidad son en gran medida similares a las normas de funcionamiento utilizadas en los sistemas de tarjetas de crédito o los sistemas de pago electrónico, que deberán poder incluir a numerosos participantes de una diversidad de jurisdicciones de acuerdo con un conjunto de normas comunes. Las reglas de funcionamiento de las tarjetas de crédito, por ejemplo, contienen disposiciones relativas a las entidades emisoras y procesadoras, los comerciantes que las aceptan y los titulares de la tarjeta, y prevén las especificaciones y reglas aplicables a los participantes en transacciones de crédito en línea y su procesamiento ulterior³⁷. Asimismo, las normas de funcionamiento de los sistemas de transferencia electrónica de fondos regulan las responsabilidades de todos los bancos que intervienen en el proceso de pago y, en medida limitada, las de los consumidores y otros pagadores, y estipulan las especificaciones y reglas aplicables a los participantes cuando se utilizan las transferencias electrónicas de fondos (por ejemplo, las transferencias SWIFT)³⁸ a fin de facilitar el pago en una transacción en línea.

30. Aunque se suele reconocer la necesidad de que las reglas de funcionamiento del sistema de identidad contengan normas jurídicas idóneas, su formulación es en gran medida un territorio sin explorar. Es preciso determinar y abordar numerosas cuestiones y barreras de orden jurídico.

³⁷ Las normas de funcionamiento de las tarjetas de crédito incluyen las especificaciones y reglas relacionadas con el emisor de la tarjeta de crédito (véase, por ejemplo, Visa International Operating Regulations at http://usa.visa.com/merchants/operations/op_regulations.html and the Payment Card Industry Data Security Standards - PCIDSS at www.pcisecuritystandards.org/security_standards/index.php), que tienen carácter vinculante para los bancos procesadores y los comerciantes, y los contratos entre los bancos emisores de la tarjeta de crédito y los bancos procesadores, los contratos entre los bancos procesadores y los comerciantes y los contratos entre los bancos procesadores y los titulares de la tarjeta. Además se complementan mediante leyes y reglamentos que rigen el procesamiento de tarjetas de crédito en cada jurisdicción.

³⁸ Las reglas de funcionamiento de la transferencia electrónica de fondos incluyen las especificaciones y normas aplicables a ese tipo de transacciones (por ejemplo, the Operating Rules and Guidelines of U.S.-based NACHA - The Electronic Payments Association, www.nacha.org/) que adquieren carácter vinculante para los bancos procesadores y los comerciantes, así como los contratos entre los comerciantes y los distintos pagadores. Asimismo, se complementan con leyes y reglamentos que rigen las transferencias electrónicas de fondos, como la Electronics Funds Transfer Act and Regulations E (en los Estados Unidos de América).

VI. Régimen jurídico que rige los sistemas de identidad

31. En la mayoría de las jurisdicciones, hay numerosas leyes y reglamentaciones en vigencia que tendrán una repercusión significativa desde el punto de vista reglamentario en la participación en un sistema de identidad (y que pueden imponer barreras, requisitos de cumplimiento o riesgos de responsabilidad). Además, las diferencias entre las legislaciones de diferentes jurisdicciones, vistas a la luz de la naturaleza mundial de la Internet, crean un panorama reglamentario muy variado que puede plantear de por sí un reto para la estructuración jurídica. Aunque algunas de las leyes y reglamentaciones aplicables se centran concretamente en actividades relacionadas con la identidad, la mayoría han sido formuladas en un contexto completamente ajeno a la gestión de la identidad (por ejemplo, el derecho de responsabilidad civil, el derecho contractual o el derecho de garantías). No obstante, pueden tener, una repercusión significativa, a menudo en formas que no se preveían en el momento de su adopción original.

32. Algunas de las categorías de ordenamiento jurídico aplicables a los sistemas de identidad (o a los participantes en ellos) son las siguientes:

a) La legislación que regula la exactitud de la información sobre la identidad: las actividades de los sistemas de identidad se centran en la recopilación y verificación por parte de los proveedores de identidad o de atributos de la información acerca de los sujetos y la comunicación de alguna de esa información a las partes receptoras. En tales casos la exactitud y la fiabilidad de dicha información son de importancia. Por ello, las leyes relativas al suministro de información falsa o incorrecta, ya sea intencionalmente o por negligencia, serán pertinentes para la evaluación de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los participantes en los sistemas de identidad. Entre ellas son de importancia básica las leyes del régimen de responsabilidad civil que rigen la declaración falsa por negligente, el endoso negligente y la difamación, así como las leyes sobre garantías, las leyes sobre robo de la identidad y las leyes que rigen las prácticas comerciales injustas y engañosas;

b) La legislación que regula la privacidad de la información sobre la identidad: por su propia índole, la gestión de la identidad entraña normalmente la reunión por el proveedor de identidad o sus agentes de información personal acerca de un sujeto, y su revelación a la parte receptora³⁹. Por ello, las leyes de protección de datos, las leyes sobre privacidad y otras leyes y reglamentaciones que regulan la reunión, utilización, procesamiento, transmisión y almacenamiento de datos personales tendrán una importante repercusión en las actividades de gestión de la identidad. Aunque muchas de esas leyes fueron redactadas en épocas anteriores al advenimiento de los sistemas de identidad digital y, en consecuencia, no podrían haber previsto los procesos particulares o daños potenciales inherentes a esos sistemas, pueden, con todo, tener un efecto directo en esas actividades;

c) La legislación que regula la reunión de información sobre la identidad: además de las leyes sobre privacidad y protección de los datos, las leyes que regulan la reutilización de información proveniente del sector público afecta a las empresas

³⁹ Excepto cuando el sujeto no es un ser humano, por ejemplo, cuando se trata de una persona jurídica, un dispositivo, una aplicación informática, entre otros.

que crean productos y servicios de información basados en datos recopilados masivamente por el sector público. Esas leyes pueden crear barreras jurídicas a la utilización en gran escala de los datos que mantienen los órganos del sector público en el contexto de los servicios de identidad⁴⁰;

d) La legislación que regula la seguridad de la información sobre la identidad y de los procesos conexos: muchas leyes imponen a las empresas obligaciones en lo que respecta a la seguridad de la información personal (según se define de diversas maneras en jurisdicciones diferentes y en virtud de leyes concretas de un sector determinado) y otros datos en su poder. Además de las leyes y reglamentaciones que imponen la obligación de aplicar medidas de seguridad para proteger los datos, muchas jurisdicciones han promulgado también leyes y reglamentaciones que imponen la obligación de revelar a las personas afectadas las violaciones de la seguridad relacionadas con su información personal;

e) La legislación relativa a la obligación de determinar la identidad: muchas leyes y reglamentaciones exigen la identificación, como elemento constitutivo de una transacción, en particular en un entorno electrónico. Por ejemplo, la Convención sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas requiere expresamente la determinación de identidad como elemento de una firma electrónica jurídicamente vinculante. En concreto, cuando la ley requiera que una parte firme una comunicación o un contrato, la Convención estipula que el requisito de la firma se dará por cumplido si se utiliza un método para determinar la identidad de esa parte y para indicar la voluntad que tiene tal parte respecto de la información consignada en la comunicación electrónica⁴¹;

f) La legislación relativa a la obligación de autenticación: varias leyes regulan uno o más elementos de la autenticación. Algunas imponen a las empresas la obligación de proceder a la autenticación de las personas con los que realizan transacciones a distancia y otros regulan aspectos del proceso de autenticación. Un ejemplo destacado es el requisito establecido en los Estados Unidos de América por los reguladores del sector bancario en relación con la autenticación de las actividades bancarias en línea. En concreto, las instituciones financieras que ofrecen a sus clientes productos y servicios a través de la Internet deberán utilizar métodos eficaces para autenticar la identidad de los clientes que utilizan esos productos y servicios⁴². Otros países (por ejemplo Singapur) también han adoptado requisitos similares⁴³;

g) La legislación que regula específicamente las actividades de los sistemas de identidad: algunas jurisdicciones cuentan con estatutos que regulan expresamente algunos aspectos de las actividades de gestión de la identidad. Un ejemplo es la

⁴⁰ Véase, de manera general, Global Networking of Individuals (GINI), Legal provisions for Deploying INDI Services (5 de octubre de 2011) Sección 5, en www.gini-sa.eu/images/stories/2011.11.06_GINI_D3.1_Legal%20Provisions%20for%20Deploying%20INDI%20Services_FINAL.pdf.

⁴¹ Convención sobre la Utilización de Comunicaciones Electrónicas, artículo 9, 3).

⁴² Federal Financial Institutions Examination Council ("FFIEC"), "Authentication in an Internet Banking Environment", 12 de octubre de 2005, pág. 1; se puede consultar en www.ffiec.gov/pdf/authentication_guidance.pdf.

⁴³ Monetary Authority of Singapore, circular núm. SRD TR 02/2005, 25 de noviembre de 2005.

Directiva de la Unión Europea sobre firmas electrónicas⁴⁴, que estipula que los Estados miembros deben regular la reunión de datos personales por parte de determinados proveedores de identidad (llamados proveedores de servicios de certificación) y reglamentar la expedición de credenciales⁴⁵. De igual manera, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas (artículos 8 a 12) establece reglas para la expedición y utilización de las credenciales de identidad requeridas para la creación de determinadas firmas electrónicas.

H. Problemas y barreras jurídicas

33. Las leyes y reglamentaciones existentes de los tipos indicados anteriormente, al igual que otras, plantean varios problemas básicos para la creación y funcionamiento de sistemas de identidad en el sector privado. Entre esos problemas cabe mencionar los siguientes:

a) Legislación no escrita para abordar la gestión de la identidad: la legislación vigente simplemente no se ocupa de muchas de las cuestiones de reciente aparición que plantean los procesos de gestión de la identidad digital. La mayor parte de las leyes existentes que se aplican en esos contextos no fueron redactadas desde la perspectiva de los sistemas de identidad digital y, por tanto, abordan o reglamentan inadecuada o inapropiadamente las actividades pertinentes. Por ejemplo, la legislación en vigor suele pasar por alto la obligación que debe cumplir el certificador de la identidad de proceder con la debida cautela al evaluar la autenticidad de los documentos de prueba de la identidad, o el alcance de la obligación de proporcionar información que el proveedor de la identidad tiene con el titular de los datos;

b) Incertidumbre/ambigüedad jurídica: si bien hay algunas cuestiones relacionadas con la gestión de la identidad digital que posiblemente estén contempladas en las leyes y reglamentaciones vigentes, frecuentemente la aplicabilidad de esas leyes no está clara o es ambigua, lo que deja en los participantes en los sistemas de identidad un grado considerable de incertidumbre jurídica, que puede retardar el crecimiento, la innovación y la inversiones. Incluso cuando las leyes vigentes se aplican a la gestión de la identidad, la manera en que se aplican a una cuestión concreta o un enfoque propuesto de un sistema de identidad tal vez no sea clara. Esta afirmación es particularmente válida en relación con las leyes que se centran en una tecnología concreta. Ello puede limitar la capacidad de las partes que conciertan transacciones relacionadas con la identidad para evaluar y gestionar los riesgos que asumen al hacerlo;

c) Cuestiones de privacidad: por su propia naturaleza, en la gestión de la identidad comúnmente un proveedor de la identidad reúne determinada información personal acerca de un sujeto y la da a conocer a la parte receptora. Para participar en un sistema de identidad, los sujetos deben revelar información personal y exponerse así al riesgo de que la información se utilice sin su autorización o en forma

⁴⁴ Directiva 1999/93/CE por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica (“Directiva de la Unión Europea sobre firmas electrónicas”), artículos 6 a 8 y Anexos I y II, que se puede consultar en http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_013/l_01320000119en00120020.pdf.

⁴⁵ Directiva de la Unión Europea sobre firmas electrónicas, artículo 8.

indebida. Además, puesto que los sujetos interactúan con múltiples partes receptoras, la comunicación o verificación requeridas de su información por parte del proveedor de la identidad le permite a este rastrear las actividades de cada sujeto, lo que da pie a preocupaciones acerca de la reunión y utilización de la información relacionada con cada transacción. La privacidad es, por tanto, una cuestión básica de todo sistema de identidad digital, que puede entrañar el planteamiento de cuestiones como: i) el tipo de información que puede reunir el proveedor de la identidad; ii) la cantidad de información que se podrá revelar a las partes receptoras; iii) el control que el sujeto tiene respecto de la revelación de la información; iv) el nivel de seguridad que deben tener los datos que manejan las partes; y v) los límites que se aplican al empleo de la información por parte del proveedor de la identidad y las partes receptoras. Esas cuestiones están con frecuencia previstas en las leyes vigentes, que podrán también complementarse mediante reglas operativas basadas en un contrato;

d) Cuestiones de responsabilidad: una preocupación de orden jurídico de importancia fundamental para los participantes en todo sistema de identidad es la de determinar quién asumirá la responsabilidad asociada con cualquiera de los riesgos (véase párr. 24 *supra*). Se han planteado numerosas teorías de derecho consuetudinario, estatutario y contractual para determinar, definir y esclarecer la fuente y el alcance de esas posibles responsabilidades⁴⁶. Con todo, esos riesgos jurídicos con frecuencia no están bien definidos y son inciertos. Las preocupaciones en torno a la responsabilidad jurídica representan una barrera básica para el sector privado a la hora de adoptar soluciones interoperables en materia de identidad digital. Con frecuencia el mejor criterio es abordar las cuestiones relacionadas con la responsabilidad mediante reglas operativas u otras formas de acuerdo contractual entre los participantes, en vista particularmente de que ese enfoque permite la “personalización” de los contratos necesaria para establecer una distribución de riesgos idónea, que habrá de variar de un caso a otro;

e) Variaciones y conflictos jurisdiccionales: hay algunas cuestiones básicas respecto de las cuales la aplicación de las leyes y reglamentaciones vigentes a las actividades relacionadas con la identidad varía considerablemente entre las distintas jurisdicciones. Así ocurre a menudo respecto de las leyes que rigen la responsabilidad del participante y las leyes de protección de datos que regulan la privacidad de la información personal. Además, en algunos casos, la regulación o la concesión de licencias de actividades de los sistemas de identidad pueden plantear barreras adicionales al funcionamiento de los sistemas de identidad a nivel transfronterizo. En consecuencia, cuando los sistemas de identidad funcionan más allá de las fronteras jurisdiccionales, el hecho de que las leyes y reglamentaciones vigentes varíen (con frecuencia considerablemente) entre jurisdicciones agravan las dificultades de la formulación de reglas de funcionamiento adecuadas;

f) Necesidad de interoperabilidad jurídica: los sistemas de identidad se ven ante el problema que plantea el hecho de que las leyes aplicables pueden diferir de una jurisdicción a otra. A falta de leyes uniformes que regulen esas actividades, los

⁴⁶ Véase *Certification Authority Liability Analysis* (estudio preparado para la American Bankers Association, en el que se examinan los posibles riesgos en materia de responsabilidad de un proveedor de identidades que actúa como autoridad de certificación); se puede consultar en <http://64.78.35.30/article/ca-liability-analysis.pdf>.

sistemas de identidad tratan de resolver el problema elaborando reglas de funcionamiento que prevean la interoperabilidad en todo el sistema. La variación de leyes y reglamentaciones entre jurisdicciones dificultará la elaboración de esas reglas de funcionamiento y de otros contratos que son necesarios para lograr que la actuación de los participantes en el sistema sea más uniforme entre sistemas en línea;

g) Restricciones de la capacidad de modificar la legislación por contrato: algunas de las leyes y reglamentaciones vigentes pueden ser modificadas mediante contrato. Por ejemplo, muchos estatutos incorporan doctrinas de derecho comercial o contractual que simplemente establecen “reglas supletorias” que se aplican cuando no ha habido una elección expresa por las partes en una transacción, aunque permiten su modificación mediante acuerdo entre ellas. En tales casos, las partes en el sistema de identidad están en libertad de modificar las reglas supletorias y subsanar los vacíos mediante la aplicación de reglas de funcionamiento apropiadas de base contractual. Sin embargo, en otros casos no se puede hacer caso omiso de normas de derecho imperativas mediante el simple acuerdo de las partes, puesto que esas reglas cumplen finalidades de política pública como la protección de los consumidores o de terceros.

34. En consecuencia, las leyes vigentes pueden crear barreras a la adopción de sistemas de identidad eficientes, interoperables y fiables que puedan funcionar a nivel transfronterizo. La formulación de reglas de funcionamiento de un sistema de identidad digital basadas en contratos es el método principal de abordar esas dificultades jurídicas y reducir la incertidumbre para los participantes. Asimismo, facilita la experimentación con sistemas diferentes y criterios diferentes a medida que el mercado se ocupa de resolver la cuestión de la gestión de la identidad digital.

35. Todos los participantes en un sistema de identidad federado tienen interés tanto en la distribución equitativa, por anticipado, de los riesgos de responsabilidad que se derivan de la participación en el proceso como en la mitigación de esos riesgos en la medida posible. Si no se determina la forma en que se debe distribuir la responsabilidad o quién está en mejores condiciones de asumir los riesgos, las incertidumbres jurídicas existentes seguirán siendo una gran barrera para la aplicación de un sistema de identidad fiable. A medida que los procesos de gestión de la identidad digital se utilicen para transacciones más importantes y los riesgos para las partes aumenten en forma acorde, cobrarán importancia los beneficios que tiene para todas las partes la aplicación de reglas de funcionamiento apropiadas para abordar esos riesgos anticipadamente y mitigarlos (en la medida posible) estipulando que cada participante cumpla obligaciones concretas.

36. De cara al futuro el reto es crear sistemas de identidad digital aplicables a las transacciones comerciales en el sector privado, a escala transfronteriza y en forma interoperable. Al igual que los sistemas de tarjetas de crédito y pagos electrónicos, las reglas de funcionamiento de los sistemas de identidad habrán de basarse probablemente en arreglos contractuales, sobre todo en la medida en que se tenga la intención de aplicarlas a nivel de la Internet sobrepasando las fronteras jurisdiccionales. Tal vez sea oportuno plantearse el examen de legislación destinada a eliminar las barreras a esos sistemas (y no a reglamentarlos).

* * *

DEFINICIONES

[NOTA: Las presentes definiciones son de carácter general y se consignan exclusivamente para ayudar a comprender el texto anterior]

Atributo: Cualidad o característica identificada inherente o adscrita a un sujeto como, en el caso de una persona física, el nombre, dirección, edad, sexo, cargo, sueldo, patrimonio neto, número de la licencia de conducir y número de seguridad social, entre otras, y en el caso de un dispositivo, marca y modelo, número de serie, ubicación y capacidad, entre otras. Sinónimos: atributo de identidad.

Autenticación: proceso de verificación de la identidad que un sujeto afirma poseer mediante la confirmación de su vinculación con la credencial. Por ejemplo, al introducir una contraseña que esté vinculada a un nombre de usuario se supone que de esa manera se verifica que el usuario es realmente la persona a la que se asignó dicho nombre. De igual manera, al comparar el aspecto de una persona que presenta un pasaporte con la fotografía que aparece en el documento se verifica o confirma que se trata efectivamente la persona descrita en él.

Autenticador: Indicador referente que se utiliza para verificar la relación entre un sujeto y una credencial; suele ser un objeto, un elemento de conocimiento o alguna característica del poseedor que se utiliza para vincular a la persona con una credencial de identidad. Por ejemplo, una contraseña hace las veces de autenticador de la identidad del usuario y una fotografía sirve como autenticador de un pasaporte o una licencia de conducir.

Autorización: proceso de otorgamiento de derechos y privilegios a los sujetos que han sido objetos de autenticación basándose en criterios determinados por la parte receptora; su finalidad es controlar el acceso a la información o los recursos de modo que solo tengan acceso a ellos las personas a las que esté expresamente permitido utilizarlos.

Credencial: datos presentados como prueba de la identidad que declara un sujeto. Entre los ejemplos de credenciales en papel cabe citar el pasaporte, la partida de nacimiento, la licencia de conducir y la tarjeta de identificación de un empleado. Entre los ejemplos de credenciales digitales figuran los nombres de usuario, las tarjetas inteligentes y los certificados digitales.

Gestión de la identidad: procesos, funciones y capacidades de reunir, verificar e interrelacionar información de identidad acerca de un sujeto y comunicarla a una parte receptora a fin de que esta pueda comprobar que la información de identidad recibida corresponde al sujeto concreto de que se trate.

Identidad: información acerca de un sujeto concreto en forma de uno o más atributos que permiten que el sujeto sea debidamente diferenciado en un contexto particular. Es el conjunto de los atributos de una persona que permiten distinguirla de las demás en un contexto determinado.

Identificación: proceso de reunión, verificación y validación de información de atributos adecuada acerca de un sujeto concreto para definir y confirmar su identidad en un contexto específico. (Sinónimos: registro; comprobación de identidad)

Parte receptora: la persona física o entidad jurídica que se basa en la credencial de identidad o la aseveración de identidad para decidir las medidas que deberá tomar

en un contexto de aplicación determinado, por ejemplo, procesar una transacción o autorizar el acceso a información o a un sistema. (Sinónimo: proveedor de servicios)

Proveedor de atributos: entidad que actúa como fuente autorizada de uno o más atributos de la identidad de un sujeto y tiene a su cargo los procesos relacionados con la reunión y mantenimiento de los datos sobre esos atributos. Un proveedor de atributos corrobora la fiabilidad y validez de las aseveraciones sobre los atributos, en respuesta a solicitudes de información sobre esos atributos formulados por los proveedores de la identidad y las partes receptoras. Como ejemplos de proveedores de atributos cabe citar el registro oficial de títulos de propiedad, una agencia nacional de información sobre solvencia crediticia o una base de datos comercial de marketing.

Proveedor de identidad: entidad encargada de la identificación de personas, físicas entidades jurídicas, dispositivos y objetos digitales, de la expedición de las credenciales de identidad correspondientes y del mantenimiento y la gestión de la información sobre la identidad de los distintos sujetos. (Sinónimos: proveedor de servicios de credenciales; autoridad de certificación; proveedor de atributos (cuando se suministran datos limitados sobre atributos))

Reglas de funcionamiento: procesos comerciales, especificaciones técnicas y normas jurídicas definidas por contrato que rigen el funcionamiento de un sistema de identidad concreto. Suelen ser elaboradas a nivel privado (por ejemplo, por el operador del sistema de identidad) y en virtud del contrato adquieren carácter vinculante y fuerza legal para los participantes. (Sinónimos: marco de confianza; normas del sistema; reglas comunes de funcionamiento; reglamentos de funcionamiento)

Sistema de identidad: entorno en línea utilizado para la gestión de la identidad digital que se rige por un conjunto de reglas de funcionamiento y en el que puede haber confianza recíproca entre individuos, organizaciones, servicios y dispositivos dado que fuentes autorizadas han establecido y autenticado sus identidades respectivas.

Sistema de identidad federado: sistema de identidad en el que un sujeto puede utilizar una credencial de identidad expedida por cualquiera de los distintos proveedores de identidad a efectos de autenticación en sistemas diferentes ante múltiples partes receptoras no relacionadas entre sí.

Sujeto: la persona física, entidad jurídica, dispositivo u objeto digital que es objeto de identificación en una credencial concreta y cuyos datos el proveedor de la identidad puede autenticar y certificar. (Sinónimo: sujeto de datos; usuario)

**E. Informe del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico
sobre la labor realizada en su 47º período de sesiones
(Nueva York, 13 a 17 de mayo de 2013)**

(A/CN.9/768)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-6
II. Organización del período de sesiones.	7-12
III. Deliberaciones y decisiones	13
IV. Proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos.	14-114
A. Observaciones generales.	14-16
B. Proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos. . .	17-111
C. Labor futura.	112-114
V. Asistencia técnica y coordinación	115
VI. Otros asuntos.	116

I. Introducción

1. En su 42º período de sesiones, celebrado en 2009, la Comisión pidió a la Secretaría que preparara un estudio sobre los documentos transmisibles electrónicos teniendo en cuenta las propuestas recibidas durante ese período de sesiones (A/CN.9/681 y Add.1 y A/CN.9/682)⁴⁷.

2. En su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión tuvo a su disposición más información sobre el empleo de las comunicaciones electrónicas para la transmisión de derechos reales sobre mercancías, con especial énfasis en las ventajas que ofrece la inscripción registral para la creación y transmisión de tales derechos (A/CN.9/692, párrs. 12 a 47). En ese período de sesiones, la Comisión pidió a la Secretaría que organizara un coloquio sobre los temas pertinentes, a saber, los documentos transmisibles electrónicos, la gestión de datos de identificación personal, el comercio electrónico por conducto de dispositivos móviles y los sistemas electrónicos de ventanilla única⁴⁸.

3. En su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión tuvo ante sí una nota de la Secretaría (A/CN.9/728 y Add.1) en la que se resumían las deliberaciones del coloquio sobre el comercio electrónico (Nueva York, 14 a 16 de febrero

⁴⁷ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párr. 343.*

⁴⁸ *Ibid.*, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), párr. 250.

de 2011)⁴⁹. Tras deliberar, la Comisión encomendó al Grupo de Trabajo que realizara actividades en el ámbito de los documentos transmisibles electrónicos⁵⁰. Se recordó que esa labor sería útil no solo para promover en general las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional, sino también para ocuparse de ciertos aspectos concretos, como el modo de contribuir a la aplicación de las Reglas de Rotterdam⁵¹. Además, la Comisión convino en que la labor relativa a los documentos transmisibles electrónicos podía abarcar determinados aspectos de otros asuntos, como la gestión de datos de identificación personal, el comercio electrónico por conducto de dispositivos móviles y los sistemas electrónicos de ventanilla única⁵².

4. En su 45º período de sesiones (Viena, 10 a 14 de octubre de 2011), el Grupo de Trabajo inició su labor sobre diversas cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos transmisibles electrónicos, entre ellas la posible metodología para la labor futura del Grupo de Trabajo (A/CN.9/737, párrs. 14 a 88). También examinó la labor realizada por otras organizaciones internacionales en relación con este tema (A/CN.9/737, párrs. 89 a 91).

5. En su 45º período de sesiones, celebrado en 2012, la Comisión expresó su reconocimiento al Grupo de Trabajo por los progresos realizados y encomió la labor de la Secretaría⁵³. La idea de que el Grupo de Trabajo prosiguiera su labor sobre los documentos transmisibles electrónicos recibió un apoyo generalizado, y se subrayó la necesidad de un régimen internacional que facilitara la utilización transfronteriza de esos documentos⁵⁴. En ese contexto, se señaló la conveniencia de definir tipos concretos de documentos transmisibles electrónicos o cuestiones concretas relacionadas con esos documentos y centrarse en ellos⁵⁵. Tras deliberar, la Comisión reafirmó el mandato del Grupo de Trabajo sobre los documentos transmisibles electrónicos y pidió a la Secretaría que siguiera informando sobre las novedades de interés relativas al comercio electrónico⁵⁶.

6. En su 46º período de sesiones (Viena, 29 de octubre a 2 de noviembre de 2012), el Grupo de Trabajo prosiguió su examen de las cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos transmisibles electrónicos. El Grupo de Trabajo confirmó la conveniencia de proseguir la labor relacionada con los documentos transmisibles electrónicos y la posible utilidad de la orientación sobre esa cuestión, y en general se opinó que deberían formularse reglas generales basadas en un enfoque funcional que abarcaran diversos tipos de documentos transmisibles electrónicos (A/CN.9/761, párrs. 17 y 18). Posteriormente, el Grupo de Trabajo examinó diversas cuestiones jurídicas que se planteaban durante el ciclo vital de los documentos transmisibles electrónicos (A/CN.9/761, párrs. 24 a 89). En cuanto a la labor futura, se expresó amplio apoyo a la preparación de proyectos de disposición relativos a

⁴⁹ En la fecha de preparación del presente documento, podía consultarse información sobre el coloquio en www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/electronic-commerce-2010.html

⁵⁰ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17)*, párr. 238.

⁵¹ *Ibid.*, párr. 235.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid. sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17)*, párr. 82.

⁵⁴ *Ibid.*, párr. 83.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, párr. 90.

documentos transmisibles electrónicos que deberían presentarse en forma de una ley modelo, sin perjuicio de la decisión que el Grupo de Trabajo adoptara sobre la forma de su labor (A/CN.9/761, párrs. 90 a 93).

II. Organización del período de sesiones

7. El Grupo de Trabajo, integrado por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 47º período de sesiones en Nueva York del 13 al 17 de mayo de 2013. Asistieron representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Argelia, Armenia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Croacia, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Grecia, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Malta, México, Pakistán, República Checa, República de Corea, Singapur, Tailandia, Turquía, Ucrania y Venezuela (República Bolivariana de).

8. Asistieron también al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Andorra, Bélgica, Hungría, Indonesia, Kuwait, Omán, República Democrática del Congo y Suecia.

9. Asistieron también al período de sesiones observadores de las siguientes organizaciones internacionales:

a) *Organizaciones intergubernamentales*: Organización Mundial de Aduanas (OMA);

b) *Organizaciones internacionales no gubernamentales*: American Bar Association, Asociación Europea de Estudiantes de Derecho, Comité Marítimo Internacional, Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios, Moot Alumni Association, New York State Bar Association y Unión Internacional de Abogados.

10. El Grupo de Trabajo eligió a los siguientes miembros de la Mesa:

Presidente: Sr. Agustín MADRID PARRA (España)

Relator: Sr. Atsushi KOIDE (Japón)

11. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí los siguientes documentos: a) Programa provisional anotado (A/CN.9/WG.IV/WP.121); y b) Nota de la Secretaría sobre los proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos (A/CN.9/WG.IV/WP.122).

12. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:

1. Apertura del período de sesiones.
2. Elección de la Mesa.
3. Aprobación del programa.
4. Examen de los proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos.
5. Asistencia técnica y coordinación.

6. Otros asuntos.
7. Aprobación del informe.

III. Deliberaciones y decisiones

13. El Grupo de Trabajo inició sus deliberaciones sobre las cuestiones jurídicas relativas al empleo de documentos transmisibles electrónicos basándose en el documento A/CN.9/WG.IV/WP.122. Las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo sobre esos temas se recogen en el capítulo IV *infra*. Se pidió a la Secretaría que revisara los proyectos de disposición para que reflejaran esas deliberaciones y decisiones.

IV. Proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos

A. Observaciones generales

14. El Grupo de Trabajo celebró un debate general sobre su labor y reafirmó que se debía guiar en su trabajo por los principios de equivalencia funcional y neutralidad respecto de los medios tecnológicos, y que no debía tratar cuestiones que se regían por el derecho sustantivo. Se señaló que la labor del Grupo debería ajustarse, en general, a los textos existentes de la CNUDMI, tener en cuenta la coexistencia de las prácticas del comercio electrónico y el comercio basado en papel, y facilitar la conversión entre esos dos tipos de medios.

15. Se indicó que habría una interacción entre las normas que posibilitaban el empleo de documentos transmisibles electrónicos y las disposiciones generales sobre el empleo de transacciones electrónicas, y que era muy de desear que continuara la armonización de esas disposiciones generales, en particular mediante una adopción más amplia de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (Nueva York, 2005) (“Convención sobre Comunicaciones Electrónicas”).

16. Se señaló que las deliberaciones futuras del Grupo de Trabajo se beneficiarían de un estudio que ofreciera un análisis comparativo de las leyes sustantivas de diversas jurisdicciones en las esferas pertinentes para su labor y abarcara diferentes tipos de documentos o instrumentos transmisibles. Sin embargo, se indicó que un estudio de esa índole requeriría recursos considerables y que el examen a fondo de las cuestiones relacionadas con el derecho sustantivo tal vez fuera más apropiado en una etapa ulterior.

B. Proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos

Proyecto de artículo 1. Ámbito de aplicación

17. El Grupo de Trabajo entabló un debate sobre la conveniencia de incluir en el alcance de los proyectos de disposición instrumentos que solo existían en el entorno electrónico.

18. De acuerdo con una opinión, esos instrumentos deberían quedar excluidos ya que el mandato del Grupo de Trabajo se limitaba a regular la transposición de los documentos de un entorno de papel a un entorno electrónico y a establecer normas que permitieran lograr la equivalencia funcional. Se señaló, además, que un debate sobre esos instrumentos entrañaría cuestiones de derecho sustantivo.

19. Según otra opinión, esos instrumentos se deberían incluir basándose en un criterio funcional. En otras palabras, mientras que esos instrumentos cumplieran las mismas funciones o funciones similares a las de los documentos o instrumentos transmisibles en papel, se deberían incluir en el ámbito de aplicación de los proyectos de disposición. Se señaló que ese enfoque ofrecería una mayor flexibilidad al ocuparse de prácticas comerciales que no existían en un entorno de papel.

20. La cuestión se planteó con respecto a la compatibilidad entre el empleo de documentos transmisibles electrónicos, por una parte, y las disposiciones contenidas en el Convenio estableciendo una Ley uniforme referente a las letras de cambio y pagarés a la orden (Ginebra, 7 de junio de 1930) y el Convenio estableciendo una Ley uniforme en materia de cheques (Ginebra, 19 de marzo de 1931). Se indicó que las disposiciones de esos Convenios, basadas en el entorno de papel, no eran compatibles con el empleo de documentos transmisibles electrónicos y que, por consiguiente, las letras de cambio, los pagarés y los cheques debían excluirse del ámbito de los proyectos de disposición.

21. En respuesta, se señaló que se habían desarrollado técnicas legislativas adecuadas para ocuparse de la cuestión de la equivalencia funcional entre el formato escrito y el formato electrónico. Se mencionó el ejemplo de la interacción entre la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas y la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958). Se propuso, por consiguiente, que las letras de cambio, los pagarés y los cheques se incluyeran en el ámbito de aplicación de los proyectos de disposición. Se señaló además que un objetivo constante del Grupo de Trabajo había sido el establecimiento de la equivalencia funcional para superar los obstáculos al empleo de medios electrónicos que se derivaban de disposiciones existentes que requerían el empleo de documentos en papel.

22. Con respecto al párrafo 2, se indicó que, al menos en algunas jurisdicciones, la aplicación de las leyes concebidas para transacciones con documentos en papel se hacía extensiva a las transacciones electrónicas y que, por consiguiente, era preciso tratar de evitar el dar prelación excesiva a esa aplicación.

Proyecto de artículo 2. Exclusión

23. El Grupo de Trabajo convino en que se aclarara la expresión “equivalentes electrónicos de los valores bursátiles”, que figuraba en el párrafo 2, apartado a), a fin de referirse a “equivalentes electrónicos de los valores bursátiles como acciones, bonos y otros instrumentos financieros, incluidos los instrumentos financieros derivados”.

24. Se dijo que era necesario aclarar la frase “medios electrónicos de pago” del párrafo 2, apartado b). Se añadió que se debía tener especial cuidado de asegurarse de que la práctica de utilizar documentos transmisibles electrónicos como medios de pago no quedase excluida del ámbito de aplicación. En respuesta, se explicó que la frase tenía por objeto remitir a la exclusión contenida en el artículo 2, párrafo 1, apartado b) de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas, que se justificaba por el hecho de que esas esferas del derecho ya habían sido objeto de amplia reglamentación contractual detallada.

Proyecto de artículo 3. Definiciones

25. Se señaló que el ámbito de aplicación del proyecto de artículo 1 dependía en gran medida de la definición de los documentos transmisibles electrónicos. Por ello, el Grupo de Trabajo entabló un debate preliminar sobre la definición de las expresiones “documento o instrumento transmisible emitido en papel” y “documento transmisible electrónico” mencionadas en el proyecto de artículo 3.

26. En cuanto a la definición de “documento o instrumento transmisible emitido en papel”, se convino en que la descripción general de documentos e instrumentos transmisibles contenida en el artículo 2, párrafo 2, de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas debería ser el punto de partida del debate y como tal, el Grupo de Trabajo aprobó la definición prevista en el proyecto de artículo 3.

27. En cuanto a la definición de “documentos transmisibles electrónicos”, el Grupo de Trabajo acordó que se suprimiera la frase que figuraba entre corchetes.

28. Reflejando el debate sobre el ámbito de los proyectos de disposición (véanse los párrs. 17 a 19 *supra*), se expresaron diferentes opiniones en cuanto a la definición de “documentos transmisibles electrónicos”. En particular, se formularon propuestas basadas en un criterio funcional, abarcando con ello instrumentos que no existían necesariamente en el entorno de papel pero cumplirían funciones similares, como probar un derecho a reclamar el cumplimiento de una obligación y permitir la transmisión de derechos mediante la transmisión del documento electrónico.

29. En respuesta, se expresó la preocupación de que un criterio de esa índole solo podría hacer referencia a un número limitado de las funciones que cumplía un documento transmisible electrónico. Además, se indicó que al definir un documento transmisible electrónico como documento que acredita el derecho a exigir el cumplimiento de una obligación se entraba en el terreno del derecho sustantivo.

30. A continuación, se indicó que la definición de “documento transmisible electrónico” prevista en el proyecto de artículo 3 podría ampliarse a fin de que abarcara instrumentos que no existían en el entorno de los documentos en papel haciendo referencia a un documento electrónico que cumplía las mismas funciones que un documento o instrumento transmisible emitido en papel. Aunque ese enfoque recibió apoyo, se señaló que dicha definición no determinaría claramente las

funciones de un documento o instrumento transmisible emitido en papel. Se subrayó que en la definición era preciso abstenerse de hacer referencia a un documento o instrumento impreso a efectos de una mayor claridad y para tener en cuenta los avances tecnológicos.

31. Tras un debate, se acordó que la definición de “documento transmisible electrónico” se ampliara centrándose en la función fundamental de transferibilidad y sin hacer referencia a un documento o instrumento impreso. Por ello, el Grupo de Trabajo adoptó la hipótesis de trabajo de que en el proyecto de disposición un “documento transmisible electrónico” significaría “un documento utilizado en un entorno electrónico mediante cuya transmisión se puede transmitir el derecho a cumplir una obligación incorporado en él”. En ese contexto, se señaló que en el proyecto de artículo 3 figuraba una definición de “traspaso” de un documento transmisible electrónico por el que se entendía el traspaso del control de un documento transmisible electrónico.

32. Se convino además en que esa decisión del Grupo de Trabajo no suponía en modo alguno que el Grupo fuese a preparar disposiciones sustantivas para instrumentos que no existían en el entorno de los documentos de papel.

33. En cuanto a la definición de “emisor”, se señaló que el término debería limitarse para que se refiriera únicamente a la persona que emitía el documento transmisible electrónico y no a cualquier otra entidad que técnicamente emitiera el documento transmisible electrónico en nombre de esa persona, por ejemplo un tercero prestador de servicios. Por consiguiente, se propuso que se suprimieran de la definición las palabras que figuraban entre corchetes con aclaraciones adicionales en el sentido de que: a) un emisor podía emitir un documento transmisible electrónico recurriendo a un tercero prestador de servicios; y b) la definición de emisor no se aplicaría a ese tercero prestador de servicios.

34. Se propuso que se incluyeran ejemplos en las definiciones a fin de ofrecer una mayor orientación a los lectores. Se propuso además que las definiciones se presentaran siguiendo un orden lógico y no por orden alfabético, a fin de mantener la coherencia de las versiones en los diferentes idiomas.

Proyecto de artículo 4. Interpretación

35. Se sugirió que se revisara el párrafo 1 para agregar que la ley sería una promulgación de una ley modelo de origen internacional. Se sugirió el texto siguiente: “La presente Ley se deriva de una ley modelo de origen internacional. En la interpretación de la presente Ley, se deberá tener presente el origen internacional de esa ley modelo y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe”.

Proyecto de artículo 5. Autonomía de las partes

36. Se indicó que si bien el principio de autonomía de las partes era una piedra angular de los textos de la CNUDMI, su funcionamiento en relación con los documentos transmisibles electrónicos debería reflejar las limitaciones a la aplicación del mismo principio en documentos o instrumentos transmisibles emitidos en papel. Se subrayó la necesidad de respetar el principio del *numerus clausus*. Se sugirió que se adoptara un enfoque que permitiera apartarse de ciertos proyectos de disposición solo en su conjunto, y que se examinara cada proyecto de

disposición para determinar de cuáles sería posible apartarse o cuáles se podrían modificar mediante acuerdo. Se subrayó que en cualquier caso esas excepciones y modificaciones no deberían afectar a terceros.

37. En respuesta, se dijo que el principio de autonomía de las partes podría aún tener aplicación en el empleo de documentos transmisibles electrónicos y que, por consiguiente, el proyecto de artículo 5 se debería conservar entre corchetes, en espera de la verificación de las disposiciones que podrían de hecho ser derogadas o modificadas por las partes.

Proyecto de artículo 6. Requisitos de información

38. Se aclaró que el proyecto de artículo 6 no impedía la emisión de un documento transmisible electrónico al portador, según lo enunciado en el proyecto de artículo 16, párrafo 4. Se explicó también que las consecuencias jurídicas de infringir los requisitos de revelación de información contenidos en otras leyes no eran una cuestión tratada en los proyectos de disposición.

Proyecto de artículo 7. Reconocimiento jurídico de un documento transmisible electrónico

39. Se sugirió que el proyecto de artículo 7 se volviera a redactar como norma positiva. Se sugirió asimismo que se incluyera una referencia a los requisitos enunciados en los proyectos de disposición. Sin embargo, se señaló que el actual proyecto de artículo, que recogía el principio de no discriminación, estaba formulado basándose en disposiciones existentes de la CNUDMI que habían sido ya incorporadas numerosas veces en el derecho interno, y que la interpretación y aplicación de dicha norma no había planteado ningún problema particular.

Proyecto de artículo 8. Constancia por escrito

Proyecto de artículo 9. Firma

40. Se recordó que los proyectos de disposición se llevarían a la práctica en el contexto del marco legislativo general de las transacciones electrónicas (véase el párr. 15 *supra*). Se explicó que los proyectos de artículo 7, 8, 9 y 12 reproducían algunas de esas normas generales, y se propuso que estas pasaran a constituir una sección separada de los proyectos de disposición, posiblemente junto con otras normas de naturaleza similar, como las relativas al momento y lugar del envío y recepción de comunicaciones electrónicas.

41. Se sugirió que, cuando en los textos existentes de la CNUDMI hubiera formulaciones diferentes de disposiciones legislativas que trataran de la misma materia, en los proyectos de disposición se utilizaran las formulaciones más recientes, a fin de sacar pleno provecho de su perfeccionamiento. Sin embargo, se señaló que varias jurisdicciones habían incorporado a su derecho interno formulaciones anteriores de disposiciones legislativas de la CNUDMI, como, por ejemplo, las relativas a las firmas electrónicas. En respuesta, se explicó que la inserción de normas generales en los proyectos de disposición tenía por objeto brindar orientación a las jurisdicciones que aún no hubiesen adoptado legislación general sobre las transacciones electrónicas, pero que, en las jurisdicciones que ya lo hubieran hecho, las normas específicas propias de los documentos transmisibles electrónicos interactuarían con la legislación general preexistente.

42. Con respecto al proyecto de artículo 8, se sugirió que la información fuera accesible para que se pudiera utilizar como referencia ulterior también cuando figurara en un documento transmisible electrónico que no tuviera equivalente en papel.

43. Se sugirió que en los proyectos de disposición se introdujeran las definiciones de “documento electrónico” y “firma electrónica”, así como disposiciones relativas a la firma electrónica de documentos transmisibles electrónicos. En respuesta, se señaló que era preciso proceder con cautela a la hora de apartarse de definiciones existentes recogidas en textos anteriores de la CNUDMI, y que algunas de las disposiciones sugeridas entraban en el territorio del derecho sustantivo.

44. El Grupo de Trabajo acordó que las palabras “una comunicación” de los proyectos de artículo 8 y 9 se conservaran sin corchetes y que se suprimieran los demás textos que figuraban entre corchetes. El Grupo de Trabajo también acordó que los proyectos de artículo de índole general se reunieran en una sección separada.

Proyecto de artículo 10. Posesión

Proyecto de artículo 11. Entrega

45. El Grupo de Trabajo convino en que los proyectos de artículo 10 y 11, que establecían normas mínimas sobre los requisitos de posesión y entrega, eran en general aceptables, a reserva de las deliberaciones sobre los proyectos de artículo 17 y 19, que trataban de los conceptos de control y traspaso del control.

46. Con respecto a las palabras “y endoso” que figuraban entre corchetes en el proyecto de artículo 11, se señaló que la equivalencia funcional del endoso podría lograrse mediante los proyectos de artículo 8 y 9 relativos a la constancia por escrito y la firma, sin que hubiera una vinculación con la entrega. Por consiguiente, se acordó que en el proyecto de artículo 11 se suprimieran las referencias al endoso.

47. Aunque se opinó que los proyectos de artículo 10 y 11 quedarían mejor ubicados después del proyecto de artículo 19, se convino en que esos proyectos de artículo se dejaran en su lugar hasta que el Grupo de Trabajo estuviera mejor preparado para examinar la secuencia general de los proyectos de disposición.

Proyecto de artículo 12. Original

48. Se explicó que el artículo 8 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico y el artículo 9, párrafo 4, de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas, que constituían la base del proyecto de artículo 12, habían sido redactados para ocuparse de cuestiones como el carácter original de los contratos, y que el ciclo de vida de un documento transmisible electrónico merecía un enfoque diferente. En consecuencia, se propuso que en el párrafo 1, apartado a), se suprimiera la referencia a “forma definitiva”.

49. Se explicó que el equivalente funcional del concepto de original emitido en papel era de aplicación práctica limitada con respecto al empleo de documentos transmisibles electrónicos puesto que todas las necesidades de orden jurídico conexas podrían atenderse mediante el establecimiento de equivalentes funcionales de los conceptos de autenticidad, singularidad e integridad de los documentos en papel, aspectos que se trataban en los proyectos de artículo 9, 13 y 14,

respectivamente. Se señaló también que en los proyectos de artículo 12 y 14 había algunas repeticiones.

50. Tras un debate, el Grupo de Trabajo acordó conservar solo la primera parte del párrafo 1 y seguir examinando la forma en que se cumplirían esos requisitos con respecto al empleo de documentos transmisibles electrónicos una vez que hubiera examinado los proyectos de artículo pertinentes sobre singularidad, integridad y control.

Proyecto de artículo 13. Singularidad de un documento transmisible electrónico

51. Con respecto al proyecto de artículo 13, se señaló que la singularidad era un concepto que se utilizaba en el entorno de los documentos en papel, cuya finalidad era dar derecho a un único tenedor a exigir el cumplimiento de una obligación. En ese contexto, se sugirió que el proyecto de artículo 13 se suprimiera o se reformulara en función del proyecto de artículo 17 relativo al control. Aunque se sugirió además la posibilidad de fusionar el proyecto de artículo 13 con el proyecto de artículo 17, se declaró también que podría ser de utilidad conservar el proyecto de artículo 13 como artículo separado.

52. El Grupo de Trabajo decidió continuar su examen del proyecto de artículo 13 cuando debatiera el proyecto de artículo 17.

Proyecto de artículo 14. Integridad de un documento transmisible electrónico

53. El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en que el proyecto de artículo 14 era en general aceptable. Con respecto al párrafo 2, apartado a), se convino en que las palabras que figuraban entre corchetes se conservaran y se suprimieran los corchetes.

54. Se explicó que los cambios de índole puramente técnica, por ejemplo los cambios debidos a la migración de datos, no afectarían la integridad de un documento transmisible electrónico y, por tanto, deberían quedar comprendidos bajo la expresión “la adición de algún cambio” mencionada en el párrafo 2, apartado a).

55. Se preguntó si el proyecto de artículo 12 (véase el párr. 50 *supra*) podría incluir una referencia al proyecto de artículo 14. En ese contexto, se sugirió que los proyectos de artículo 12 y 14 se podrían fusionar. Sin embargo, el sentir general fue que en el proyecto de artículo 12, que era una disposición que tenía por objeto lograr la equivalencia funcional del concepto de “original” de los documentos en papel, no se debía hacer referencia al proyecto de artículo 14, que exigía la integridad de un documento transmisible electrónico como tal. Se subrayó que la “integridad” era una calidad que no estaba necesariamente vinculada al “original” y que era preciso garantizar a lo largo del ciclo de vida de un documento transmisible electrónico.

56. Tras un debate, se convino en conservar el proyecto de artículo 14 suprimiendo los corchetes en el párrafo 2. Se convino además en que los proyectos de artículo 12 y 14 se mantuvieran separados.

Proyecto de artículo 15. Consentimiento para utilizar un documento transmisible electrónico

57. Se aclaró que el párrafo 1 enunciaba simplemente el principio general de que una persona no estaría obligada a utilizar un documento transmisible electrónico, mientras que el párrafo 2 trataba del requisito de que las partes que intervenían en la utilización de documentos transmisibles electrónicos dieran el consentimiento para su utilización. Se aclaró, además, que la palabra “partes” se empleaba de manera genérica, a fin de abarcar diferentes tipos de partes afectadas. Se sugirió que el requisito de consentimiento fuera de carácter general y no se refiriera a proyectos de artículo concretos. Se indicó que el párrafo 3 trataba de casos de los que se deduciría el consentimiento de la parte, por ejemplo, cuando el cesionario de un documento transmisible electrónico obtenía el control de ese documento.

58. Tras un debate, se convino en que los párrafos 1 y 3 se conservaran en su forma actual. Se acordó además que el párrafo 2 se mantuviera todavía entre corchetes, sin hacer ninguna referencia a artículos concretos de los proyectos de disposición.

Proyecto de artículo 16. Emisión de un documento transmisible electrónico*Párrafo 1*

59. Hubo acuerdo general en que el párrafo 1 era aceptable. Además, se sugirió que el párrafo 1 no sería necesario si se mantenía el párrafo 2 del proyecto de artículo 15 de los proyectos de disposición (véanse los párrafos 57 y 58 *supra*).

60. Se señaló que si bien el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo (Nueva York, 2008) (“Reglas de Rotterdam”) exigía el consentimiento del porteador y del cargador para la emisión y utilización ulterior de un documento de transporte electrónico, permitía la emisión de un documento de transporte electrónico no solo al cargador, sino también al cargador documentario o el destinatario. Se preguntó, por consiguiente, si, con arreglo al párrafo 1 del proyecto de artículo 16, el primer tenedor cuyo consentimiento se requería sería el porteador y no la persona a la que de hecho se emitía el documento transmisible electrónico. En respuesta, se explicó que con arreglo al párrafo 1, el primer tenedor podría ser el porteador, el porteador documentario o el destinatario, según el caso.

61. Se explicó además que, en determinados casos, un documento o instrumento transferible impreso cumplía múltiples funciones, algunas de las cuales no dependían de la transferibilidad del documento o instrumento. Por ejemplo, un conocimiento de embarque legitima al tenedor a obtener la entrega de las mercancías y demuestra también el contrato de transporte de mercancías por mar entre el cargador y el porteador. Se indicó que en tales casos se aplicarían requisitos diferentes para lograr la equivalencia con las diversas funciones de un documento o instrumento transferible impreso.

Párrafo 2

62. Se indicó que determinada información que se requería para la emisión de un documento o instrumento impreso transferible tal vez no fuera necesariamente pertinente respecto de un documento transmisible electrónico. Por consiguiente, se propuso que el párrafo se suprimiera o se revisara en consecuencia.

63. Se señaló que la información requerida en un documento transmisible electrónico debería corresponder a la información requerida en el documento o instrumento transferible impreso cuyas funciones se buscaba que cumpliera el documento transmisible electrónico.

64. Se subrayó que una de las finalidades del párrafo era evitar que se solicitara más información para la emisión de un documento transmisible electrónico que para la emisión de su equivalente en papel, lo cual podría traducirse en la discriminación contra el empleo de medios electrónicos.

65. Se pidió a la Secretaría que revisara el párrafo 2 teniendo en cuenta las sugerencias anteriores.

Párrafo 3

66. Se indicó que, a lo largo de su ciclo de vida, un documento transmisible electrónico podría contener información adicional a la contenida en el documento o instrumento transferible impreso que cumplía las mismas funciones. Se convino en que se preparara un proyecto de artículo separado teniendo en cuenta esa consideración.

Párrafo 4

67. Se convino en que se revisara el párrafo 4 para aclarar que tenía por objeto permitir la emisión de un documento transmisible electrónico al portador en circunstancias en que esa emisión estaría permitida se tratara de un documento o instrumento impreso transferible.

Párrafo 5

68. Hubo amplio acuerdo en que el párrafo 5 debía suprimirse ya que el derecho sustantivo determinaría el momento de emisión de un documento transmisible electrónico. Sin embargo, en vista de que el momento de la emisión tenía consecuencias importantes en la práctica comercial, se sugirió que el párrafo 5 se mantuviera, mejorándolo para aclarar la interacción entre los requisitos de derecho sustantivo, por una parte, y las normas generales de la legislación relativa a las transacciones electrónicas pertinentes para la determinación del momento de la emisión, por otra.

69. Tras un debate, se convino en que se suprimiera el párrafo 5 en su forma actual, aunque con la posibilidad de introducir un párrafo similar que no guardara relación con el derecho sustantivo.

Párrafo 6

70. Tras señalar que el párrafo 6 era una declaración de carácter general de que un documento transmisible electrónico estaría sujeto a control desde el momento en que fuera emitido hasta que perdiera su validez o eficacia (por ejemplo, de conformidad con el proyecto de artículo 26), el Grupo de Trabajo convino en conservar el párrafo 6 en su forma actual.

Párrafo 7

71. Se indicó que, aunque existían prácticas comerciales en las que se emitían múltiples originales de documentos o instrumentos transmisibles emitidos en papel, no se podía encontrar ningún caso en que la ley lo exigiera. Se sugirió que se sustituyera la palabra “requiera” por la palabra “permita”.

72. Se explicó que, por lo general la ley procura mitigar las consecuencias negativas del empleo de múltiples originales. Se explicó también que las funciones que se cumplían mediante originales múltiples en el entorno de los documentos en papel podrían tener un tratamiento adecuado en un entorno electrónico mediante la utilización de diferentes métodos. Por consiguiente, se sugirió que se suprimiera el párrafo 7.

73. Sin embargo, se dijo también que una disposición del tipo de la enunciada en el párrafo 7 podría ser particularmente útil en caso de que un documento o instrumento transmisible emitido en papel en múltiples originales se sustituyera por un documento transmisible electrónico. A ese respecto, se propuso que el párrafo 7 se reformulara para declarar que todos los tenedores de un documento o instrumento transmisible emitido en papel en múltiples originales deberían establecer el control del documento transmisible electrónico resultante.

74. Si bien se reconoció la práctica comercial de emitir originales múltiples, se convino en que el párrafo 7 en su forma actual se suprimiera. Se pidió a la Secretaría que proporcionara ejemplos de circunstancias en que esas prácticas existían y eran permitidas con arreglo al derecho sustantivo y las funciones desempeñadas por los originales múltiples y, de ser posible, que determinara dónde se podría requerir una disposición similar en otros artículos de los proyectos de disposición.

Proyecto de artículo 17. Control

75. De acuerdo con su decisión (véase el párr. 52), el Grupo de Trabajo examinó conjuntamente los proyectos de artículo 13 y 17.

76. Con respecto al proyecto de artículo 13, se formularon las siguientes sugerencias: a) el proyecto de artículo debería mantenerse separado del proyecto de artículo 17; b) las frases que figuraban entre corchetes en el párrafo 1 deberían suprimirse; c) las palabras “de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto de artículo 17” deberían sustituirse por las palabras “mediante el cual el ejemplar fehaciente sea fácilmente identificable como tal”; d) el proyecto de artículo debería formularse de nuevo para que su texto fuera similar al de otras disposiciones relativas a la equivalencia funcional comenzando con las palabras “cuando la ley requiera la singularidad”. Con respecto a la última sugerencia, se cuestionó que hubiera casos en que la ley requiriese la singularidad.

77. Según el sentir general, el concepto de control debería establecer la equivalencia funcional de la posesión con respecto a la utilización de un documento transmisible electrónico (véase el párr. 45 *supra*) y su finalidad era identificar de manera fiable al tenedor. En ese contexto, se hicieron las siguientes sugerencias con respecto al proyecto de artículo 17: a) la persona que ejerciera el control debería ser la persona que tuviera el poder *de facto* sobre el documento transmisible electrónico; b) el poder *de facto* incluiría, entre otras cosas, la facultad para manejar

el documento transmisible electrónico o disponer de él; c) la persona que tuviera el poder *de facto* podría no ser necesariamente el tenedor legítimo; d) el derecho sustantivo determinaría si la persona que tuviera el poder *de facto* era un tenedor legítimo y los derechos que se derivaban de esa condición jurídica; e) el poder *de facto* podría definirse como poder “justo, legítimo e independiente”; y f) el poder *de facto* no se debería entender como la capacidad técnica de un operador de registro o un tercero prestador de servicios para controlar datos almacenados en el registro de documentos transmisibles electrónicos.

78. Se explicó además que la persona que ejercía el control podía transmitir el documento transmisible electrónico o disponer de él aunque no fuera el tenedor legítimo. Se puntualizó que el concepto de control sobre un documento transmisible electrónico podía significar el control sobre la información relacionada con el documento transmisible electrónico (control lógico) o un objeto físico que contuviera dicha información (control físico).

79. Se sugirió que el proyecto de artículo 17 no incluyera ninguna referencia a una persona a la que se hubiera “emitido o transferido” el documento transmisible electrónico puesto que la validez de la emisión o transmisión del documento transmisible electrónico la determinaría el derecho sustantivo. En respuesta, se señaló que una formulación como la recogida en el párrafo 1 no planteaba dificultades prácticas de ningún tipo.

80. Además, se hicieron las siguientes sugerencias: a) no se deberían hacer referencias a “un ejemplar fehaciente”; b) era preciso considerar con sumo cuidado las definiciones de términos como “tenedor”, “emisión”, “traspaso” y “control” pues podían llevar a una petición de principio; c) se debería hacer referencia a “control exclusivo” en lugar de “control”; y d) un examen de ejemplos ilustrativos de la forma en que puede adquirirse el “control” en la práctica podría dar una idea de la mejor forma de redactar los proyectos de disposición sobre el control.

81. Tras un debate, se propuso que el texto del proyecto de artículo 17 fuera el siguiente: “Una persona ejerce el control de un documento transmisible electrónico si un método utilizado para probar la transmisión de derechos sobre el documento establece fehacientemente que esa persona es la que, directa o indirectamente, tiene el poder *de facto* sobre el documento, con lo cual se preserva la singularidad e integridad de ese documento de conformidad con los proyectos de artículo 13 y 14”.

82. Con respecto al párrafo 2, se sugirió que el párrafo o bien se suprimiera o se formulara de nuevo a fin de ilustrar los métodos para identificar fehacientemente a la persona que ejerce el poder *de facto* sobre el documento. En respuesta, se indicó que se debería ofrecer al menos alguna orientación, teniendo plenamente en cuenta la neutralidad tecnológica, sobre el momento y la forma en que un método cumpliría la norma de fiabilidad, y que, con ese fin, se podría utilizar una técnica de redacción similar a la empleada en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales. En ese contexto, se mencionaron como métodos de lograr la fiabilidad el criterio del ejemplar fehaciente y el criterio del registro. Se señaló que el grado de fiabilidad variaría según el sistema o los tipos de documentos y que correspondía a las partes elegir el grado de fiabilidad adecuado para sus transacciones.

83. Se señaló que los conceptos de “derecho de control” y “parte controladora” utilizados en las Reglas de Rotterdam deberían distinguirse del concepto de control examinado en las deliberaciones en curso, puesto que esos términos se relacionaban con los derechos sustantivos del tenedor de un documento transmisible electrónico (véase A/CN.9/WG.IV/WP.122, párr. 30).

84. Como observación de redacción, se sugirió que al proyecto de artículo 17 se le diera una nueva formulación, similar a la de otras disposiciones encaminadas a lograr la equivalencia funcional, o que se fusionara con el proyecto de artículo 10 para que comenzara con las palabras “cuando la ley requiera la posesión”, sin hacer ninguna referencia a la posesión del documento o instrumento transmisible emitido en papel. En respuesta, se señaló que incluso en ese caso sería necesario establecer un vínculo entre la “ley” y el documento transmisible electrónico, puesto que no se trataría de un requisito general en virtud de la ley, sino más bien en virtud de la ley que regía para el documento o instrumento transmisible emitido en papel, cuyas funciones estaba destinado a cumplir el documento transmisible electrónico.

85. Tras un debate, se convino en que: a) la equivalencia funcional de la posesión se cumpliría mediante el control; b) el proyecto de artículo 17 no debería tratar los derechos sustantivos conferidos a la persona que ejercía el control sobre un documento transmisible electrónico; c) el concepto de singularidad y el concepto de control merecían proyectos de artículo separados, si bien se podría hacer remisión de un artículo al otro; d) el método utilizado para establecer el control debería ser un método que identificara al tenedor *de facto* de un documento transmisible electrónico, en tanto que la cuestión de si el tenedor era un tenedor legítimo se dejaría al derecho sustantivo; y e) se debería considerar la posibilidad de combinar los proyectos de artículo 10 y 17.

Proyecto de artículo 18. Tenedor

86. Se señaló que en el párrafo 1 simplemente se repetía la definición de “tenedor” que figuraba en el proyecto de artículo 3 y se sugirió que bastaba con esa definición. Se señaló que seguir elaborando la disposición contenida en el párrafo 2 para llegar a una formulación más exhaustiva podría suponer una interferencia con el derecho sustantivo. Por consiguiente, se convino en suprimir el artículo 18.

Proyecto de artículo 19. Traspaso del control de un documento transmisible electrónico

87. Se sugirió que se revisara el párrafo 1 a fin de tener en cuenta los requisitos adicionales para la transmisión que podría imponer el derecho sustantivo, concretamente, el endoso o acuerdo. En respuesta a esa sugerencia, se señaló que el párrafo 1 tenía por único objetivo explicar que para transmitir el documento transmisible electrónico es necesario traspasar el control del documento. Se propuso que se adoptara una formulación positiva del proyecto de párrafo en aras de la claridad. Se añadió que el derecho sustantivo establecería posibles requisitos adicionales para la transmisión de un documento transmisible electrónico.

88. Se aclaró que el párrafo 2 tenía por objeto posibilitar la conversión de la forma de transmisión de los documentos transmisibles electrónicos, de modo que un documento transmisible electrónico emitido “al portador” pudiera transmitirse a “una persona designada” y viceversa.

89. Se señaló que la efectividad de la transmisión de un documento transmisible electrónico era una cuestión que competía al derecho sustantivo. Por consiguiente, se propuso que se suprimiera el párrafo 3. En ese contexto, también se sugirió que los proyectos de disposición no se refiriesen a los requisitos para la transmisión efectiva ni a las consecuencias de la inexistencia de dichos requisitos.

90. Se argumentó que el párrafo 4 era redundante porque en el proyecto de artículo 15, párrafo 3, ya figuraba una regla general sobre la deducción del consentimiento.

91. Se señaló que el párrafo 5 podría frustrar la función de la distribución de un documento transmisible electrónico al portador al introducir un requisito de incluir una declaración que no se prevé en el derecho sustantivo. Se añadió que exigir dicha declaración podría suponer una violación de la neutralidad respecto de los medios tecnológicos si conllevaba el uso de un modelo de registro. En respuesta a dicho argumento, se señaló que debería estudiarse la forma en que habría que efectuar el registro de la cadena de endosos de los documentos transmisibles electrónicos emitidos a nombre de una persona designada, a fin de hacer posibles las reclamaciones. Se sugirió que, en los casos en que la ley impusiera el requisito de endoso, ello podría lograrse en el entorno electrónico mediante los equivalentes electrónicos de la constancia por escrito y la firma de conformidad con los proyectos de artículo 8 y 9 y se podría incluir un artículo aparte para indicarlo.

92. Se convino en reformular el párrafo 1 para tener en cuenta las cuestiones mencionadas más arriba y en suprimir el párrafo 3. Se convino también en revisar los párrafos 2, 4 y 5 con miras a establecer la equivalencia funcional de la entrega y el endoso en un entorno electrónico.

Proyecto de artículo 20. Modificación de un documento transmisible electrónico

93. Se sugirió que podría lograrse la equivalencia funcional con respecto a la modificación de un documento transmisible electrónico introduciendo una regla según la cual, en los casos en que la ley permitiera la modificación de los documentos transmisibles electrónicos, se considerase cumplido ese requisito si se hacía constar en el documento transmisible electrónico la información modificada y si se podía identificar fácilmente dicha información.

94. Se señaló que para que una modificación fuera legítima hacían falta dos elementos, a saber, que el derecho sustantivo autorizara la modificación y que esta fuera autorizada por el tenedor del documento transmisible electrónico.

95. Se señaló que el párrafo 2 hacía referencia a un requisito de notificación a terceros que competía al derecho sustantivo. Se añadió que los proyectos de disposición debían permitir las notificaciones en todos los casos en que las exigiera el derecho sustantivo.

96. Se expresaron distintas opiniones sobre lo que podría constituir una modificación. Algunos opinaron que esta podría referirse a cualquier cambio o adición con respecto a la información contenida en el documento transmisible electrónico. Otros indicaron que debía referirse únicamente a los casos en que se cambiara el contenido de una obligación. Se insistió en que en aras de la claridad y para evitar consecuencias no deseadas, se debía precisar el significado de “modificación” y hacer una distinción neta entre una modificación de la obligación

de cumplimiento y una adición al documento transmisible electrónico, como un endoso.

97. Tras deliberar, se decidió revisar el proyecto de artículo 20 teniendo en cuenta las opiniones expresadas más arriba, prestando especial atención al logro de la equivalencia funcional.

Proyecto de artículo 21. Error en la información que figura en un documento transmisible electrónico

98. En respuesta a una pregunta, se explicó que la idea de error producido al introducir los datos se refería a un error de mecanografía cometido por una persona física al interactuar con un sistema automatizado. Se señaló que la disposición sobre los errores cometidos al introducir los datos que figuraba en el artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales se había concebido para aplicarse en un entorno muy diferente al de los documentos transmisibles electrónicos y, por tanto, podría no ser adecuada.

99. Se decidió suprimir el proyecto de artículo 21.

Proyecto de artículo 22. División de un documento transmisible electrónico

Proyecto de artículo 23. Combinación de documentos transmisibles electrónicos

100. Con respecto a los proyectos de artículo 22 y 23, se indicó que la cuestión de si los documentos transmisibles electrónicos podían dividirse o combinarse era una cuestión de derecho sustantivo, al que también competía establecer los requisitos pertinentes. En consecuencia, se afirmó que dichos artículos serían aplicables solamente cuando ello se permitiese con arreglo al derecho sustantivo. Se agregó que debía considerarse el hecho de que el entorno electrónico facilitaría la división y combinación de los documentos.

Proyecto de artículo 24. Sustitución

101. Con respecto al proyecto de artículo 24, se hicieron las siguientes sugerencias: a) toda sustitución requeriría el consentimiento de cualquier parte obligada al cumplimiento, lo cual sería determinado por el derecho sustantivo; b) la parte obligada estaría en condiciones, en todo caso, de exigir la sustitución al hacer la presentación para el cumplimiento; c) el requisito mencionado en el apartado 2 b) de que se incluya toda la información también debería mencionarse el apartado 1 b); d) también debería tenerse en cuenta la posibilidad de consentimiento previo a la sustitución (por ejemplo, al efectuar la emisión); y f) el párrafo 3 debería volver a formularse como regla general en un proyecto de artículo aparte.

Proyecto de artículo 25. [Entrega] [Presentación para el cumplimiento]

102. Con respecto al proyecto de artículo 25, se hicieron las siguientes sugerencias: a) el proyecto de artículo podía interpretarse en el sentido de que logra la equivalencia funcional del término general “presentación”; b) con arreglo al derecho sustantivo, podría haber otros requisitos de la presentación para el cumplimiento, por ejemplo, demostrar que el tenedor es el tenedor legítimo, además de presentar la cadena de endosos; c) el proyecto de artículo podría suprimirse puesto que el

proyecto de artículo 11 sobre la entrega era suficiente; d) mientras exista un procedimiento por el cual el tenedor pueda demostrar que es el tenedor legítimo, el proyecto de artículo no sería necesario; y e) tenía sentido retener el proyecto de artículo puesto que los conceptos de “entrega” o “presentación para el cumplimiento” eran diferentes de los conceptos de “presentación” o “entrega” propiamente dicha.

Proyecto de artículo 26. Cumplimiento de la obligación

103. Se convino en que se suprimiera el proyecto de artículo 26 ya que se refería a cuestiones de derecho sustantivo.

Proyecto de artículo 27. Cancelación de un documento transmisible electrónico

104. Se observó que la cuestión del momento en que un documento transmisible electrónico queda privado de su eficacia o validez es un asunto de derecho sustantivo y que, por tanto, el proyecto de artículo 27 debería limitarse a permitir la aplicación del derecho sustantivo en un entorno electrónico. Sin embargo, también se explicó que el proyecto de artículo tenía por objeto únicamente alcanzar la equivalencia funcional de la “destrucción” de un documento o instrumento transmisible emitido en papel, sin entrar a considerar las cuestiones de validez del documento transmisible electrónico. Se sugirió que se revisara el proyecto de artículo para expresar esa idea de manera más precisa.

Proyecto de artículo 28. Garantía real sobre un documento transmisible electrónico

105. Con respecto al proyecto de artículo 28 se hicieron las siguientes sugerencias: a) puesto que la constitución de una garantía real sobre ciertos tipos de documentos o instrumentos en papel se regía por la ley aplicable a dicho documento o instrumento, también debería hacerse referencia a la ley aplicable; y b) el proyecto de artículo no debería limitarse a la “constitución” de una garantía real, por lo cual podría revisarse de manera que dijera lo siguiente: “Se proporcionará un procedimiento fiable para permitir el empleo de documentos transmisibles electrónicos a efectos de una garantía real.”

Proyecto de artículo 29. Archivo de información en un documento transmisible electrónico

106. Con respecto al proyecto de artículo 29, se hicieron las siguientes sugerencias: a) debería hablarse de “conservación” más que de “archivo”; b) el apartado 1 b) debería centrar la atención en la integridad del documento más que en el formato; y c) podría explorarse más a fondo la posibilidad de tratar de la conservación electrónica de documentos o instrumentos transmisibles emitidos en papel.

Proyectos de artículo 30 a 33: Terceros prestadores de servicios

107. Con respecto a los proyectos de artículo relativos a los terceros prestadores de servicios, se opinó en general que esas disposiciones eran demasiado detalladas y podrían no respetar plenamente el principio de la neutralidad tecnológica. Se agregó que esos proyectos de disposición eran de carácter reglamentario y podrían tener el efecto de limitar la competencia. Se explicó que esos asuntos normalmente se abordaban por vía contractual cuando los intercambios tenían lugar en sistemas

cerrados, en tanto que podría hacer falta orientación cuando esos intercambios se produjeran en sistemas abiertos. Se indicó que, si se sentía la necesidad de proporcionar orientación en la materia, se prestaría la debida atención a textos recientes pertinentes, como el artículo 19 de la propuesta de “Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo sobre la identificación electrónica y los servicios de fiabilidad para las operaciones electrónicas en el mercado interno”, que trata de los requisitos que deben cumplir los prestadores cualificados de servicios de confianza.

108. Se sugirió que el inciso 1) c) ii) del artículo 31 se suprimiera. Se observó también que el término “válida”, que figuraba en el proyecto de artículo 31, no era claro.

109. Fue opinión general que el proyecto de artículo 33 trataba de cuestiones de derecho sustantivo, fuera del alcance de la labor actual y que debía suprimirse.

110. Tras un debate, se acordó que los proyectos de disposición que trataban de los terceros prestadores de servicios se revisaran a la luz de las consideraciones expuestas más arriba, teniendo presente la neutralidad tecnológica.

Proyecto de artículo 34. Reconocimiento de los documentos transmisibles electrónicos extranjeros

111. El sentir general fue que los proyectos de disposición no debían desplazar las normas existentes del derecho internacional privado aplicables a los documentos o instrumentos transmisibles emitidos en papel. Sin embargo, se agregó, el tratamiento jurídico de ciertas cuestiones privativas de la utilización de documentos transmisibles electrónicos, como la posibilidad de discriminar contra un documento transmisible electrónico extranjero en virtud de su origen exclusivamente, podría merecer cierta consideración adicional. Se acordó que el proyecto de artículo 34 se revisara con miras a reducir su alcance a las cuestiones relacionadas exclusivamente con la utilización de medios electrónicos, sin desplazar las normas generales sobre el conflicto de leyes.

C. Labor futura

112. Se observó que, si bien era prematuro empezar a examinar la forma definitiva de la labor, los proyectos de disposición eran, en gran medida, compatibles con los distintos resultados que podían alcanzarse. Sin embargo, se afirmó que debía procederse con cautela cuando se proporcionaban textos que tenían pertinencia práctica y, por tanto, daban apoyo a las prácticas comerciales existentes, sin regular posibles prácticas futuras.

113. Se expresó la opinión de que el Grupo de Trabajo debía examinar a fondo ciertas cuestiones intersectoriales que también eran pertinentes para el tratamiento de los documentos transmisibles electrónicos, como la marcación de hora y fecha y el archivo.

114. Se informó al Grupo de Trabajo de que Alemania había aprobado recientemente enmiendas a su código comercial por las cuales se permitía el uso de documentos electrónicos de transporte negociables.

V. Asistencia técnica y coordinación

115. El Grupo de Trabajo oyó un informe verbal sobre las actividades de asistencia técnica y de coordinación emprendidas por la Secretaría, incluida la promoción de los textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico. En particular, se mencionó la coordinación existente con el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y el Comercio Electrónico. Se mencionaron concretamente las iniciativas de promoción y coordinación en la región de Asia y el Pacífico, incluida la contribución de la CNUDMI a la preparación de un proyecto de arreglo o acuerdo sobre la facilitación del comercio sin soporte de papel promovido por la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) en el marco de la aplicación de la resolución 68/3 de la CESPAP.

VI. Otros asuntos

116. Se informó al Grupo de Trabajo de que se había programado la celebración del 48º período de sesiones en Viena del 9 al 13 de diciembre de 2013, a reserva de la decisión que adoptara la Comisión en su 46º período de sesiones (8 a 26 de julio de 2013) y de la confirmación de los servicios de gestión de conferencias de la Secretaría de las Naciones Unidas.

F. Nota de la Secretaría sobre proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos, presentada al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 47º período de sesiones

(A/CN.9/WG.IV/WP.122)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción.	1-3
II. Proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos	4-62
A. Disposiciones generales (Artículos 1 a 6)	4-11
B. Utilización de documentos transmisibles electrónicos (Artículos 7 a 29)....	12-57
C. Terceros prestadores de servicios (Artículos 30 a 33)	58-59
D. Reconocimiento transfronterizo de los documentos transmisibles electrónicos (Artículo 34)	60-62

I. Introducción

1. En su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión encomendó al Grupo de Trabajo que realizara actividades en el ámbito de los documentos transmisibles electrónicos¹.

2. En su 45º período de sesiones (Viena, 10 a 14 de octubre de 2011), el Grupo de Trabajo inició su labor sobre los documentos transmisibles electrónicos (A/CN.9/737, párrs. 14 a 88). En su 46º período de sesiones (Viena, 29 de octubre a 2 de noviembre de 2012), el Grupo de Trabajo prosiguió su examen de las cuestiones jurídicas que se plantean durante el ciclo vital de los documentos transmisibles electrónicos (A/CN.9/761, párrs. 24 a 89) y la preparación de proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos recibió un amplio apoyo (A/CN.9/761, párrs. 90 a 93).

3. De acuerdo con esa decisión, en la parte II de la presente nota figuran proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos, presentados en forma de una ley modelo, sin perjuicio de la decisión que el Grupo de Trabajo adopte sobre la forma de su labor (A/CN.9/761, párrs. 92 y 93).

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 238.*

II. Proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos

A. Disposiciones generales

“Proyecto de artículo 1. Ámbito de aplicación

1. La presente Ley será de aplicación a todo tipo de documento transmisible electrónico.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Ley afectará a la aplicación de cualquier norma jurídica que regule los documentos o instrumentos transmisibles emitidos en papel a los documentos transmisibles electrónicos, salvo lo dispuesto en la presente Ley.”

Observaciones

4. El párrafo 1 del proyecto de artículo 1 refleja el acuerdo del Grupo de Trabajo de que deberían formularse reglas generales basadas en un enfoque funcional que abarcaran diversos tipos de documentos transmisibles electrónicos (A/CN.9/761, párr. 18). El párrafo 2 del proyecto de artículo 1 continúa indicando que los proyectos de disposición no deben ocuparse de las cuestiones reguladas por el derecho sustantivo aplicable a los documentos o instrumentos transmisibles emitidos en papel (A/CN.9/761, párrs. 20, 28, 49, 62, 68, 71, 79 y 85).
5. Cabe remitirse a la Convención por la que se establece una ley uniforme sobre letras de cambio y pagarés (Ginebra, 7 de junio de 1930) y la Convención por la que se establece una ley uniforme sobre cheques (Ginebra, 19 de marzo de 1931). Esas Convenciones fueron preparadas en un contexto basado en el papel y únicamente presuponen la utilización de instrumentos en papel (por ejemplo, hacen referencia a la “cara” y el “dorso” del instrumento y el “cruce” de cheques). Si bien esas Convenciones no excluyen de manera expresa la utilización de equivalentes electrónicos, habría que examinar detenidamente si los Estados partes en ellas podrían introducir equivalentes electrónicos de las letras de cambio, los pagarés o los cheques.

“Proyecto de artículo 2. Exclusión

1. La presente Ley no derogará ninguna norma jurídica aplicable a la protección del consumidor.
2. La presente Ley no se aplica a lo siguiente: a) los equivalentes electrónicos de los valores bursátiles; b) los medios electrónicos de pago; y c) ... ”

Observaciones

6. El párrafo 1 del proyecto de artículo 2 es parecido al artículo 1 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas (2001) y en él se reconoce que la legislación relativa a la protección de los consumidores puede tener prioridad sobre los proyectos de disposición. El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si se debe mantener ese párrafo.

7. El párrafo 2 del proyecto de artículo 2 refleja el debate mantenido en el Grupo de Trabajo sobre el alcance de su labor (A/CN.9/761, párr. 22). El Grupo de Trabajo quizás desee seguir debatiendo el alcance de su labor, tal vez especificando instrumentos (por ejemplo, el dinero electrónico) u operaciones (por ejemplo, operaciones con divisas) que deberían quedar excluidos del ámbito de los proyectos de disposición.

“Proyecto de artículo 3. Definiciones

A los efectos de la presente Ley:

por “modificación” se entenderá la modificación de la información que figura en el documento transmisible electrónico;

por “documento transmisible electrónico” se entenderá el equivalente electrónico de cualquier documento o instrumento transmisible emitido en papel [que legitima al tenedor para exigir el cumplimiento de la obligación especificada en el documento transmisible electrónico];

por “tenedor” de un documento transmisible electrónico se entenderá la persona que ejerce el control sobre el documento transmisible electrónico de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto de artículo 17;

por “emisión” de un documento transmisible electrónico se entenderá su emisión de acuerdo con el procedimiento establecido en los proyectos de artículo 16 y 17;

por “emisor” se entenderá la persona que emite [o solicita la emisión de] un documento transmisible electrónico;

por “cumplimiento de la obligación” se entenderá la entrega de las mercancías o el pago de una suma de dinero especificados en un documento o instrumento transmisible emitido en papel o un documento transmisible electrónico;

por “documento o instrumento en papel transmisible” se entenderá todo documento o instrumento transmisible emitido en papel que legitime al portador o beneficiario para exigir el cumplimiento de la obligación especificada en el documento o instrumento transmisible emitido en papel;

por “activación” se entenderá el paso físico o técnico de colocar el documento transmisible electrónico bajo el control de su primer tenedor;

por “sustitución” se entenderá el cambio de soporte, de un documento o instrumento transmisible emitido en papel a un documento transmisible electrónico o viceversa;

por “entrega” de un documento transmisible electrónico se entenderá la presentación del documento transmisible electrónico para el cumplimiento de la obligación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25;

por “tercero prestador de servicios” se entenderá un tercero que preste servicios para la utilización de documentos transmisibles electrónicos;

por “traspaso” de un documento transmisible electrónico se entenderá el traspaso del control de un documento transmisible electrónico.”

Observaciones

8. Las definiciones que figuran en el proyecto de artículo 3 han sido preparadas como referencia y deben ser examinadas en el contexto de los proyectos de artículo correspondientes. Entre otras cosas, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si:

a) Se incluye una definición de “ejemplar fehaciente” una vez que haya debatido sobre el proyecto de artículo 17;

b) Se incluye una definición de “control” que remita al procedimiento establecido en el proyecto de artículo 17;

c) La definición de “documentos transmisibles electrónicos” refleja correctamente el acuerdo del Grupo de Trabajo de que debería posibilitar el empleo de documentos transmisibles electrónicos como equivalentes de los documentos o instrumentos transmisibles emitidos en papel existentes (A/CN.9/761, párrs. 22 y 29). En ese contexto, el Grupo de Trabajo tal vez desee seguir analizando el tratamiento de los instrumentos que existen únicamente en el entorno electrónico, en especial si hay que excluirlos del ámbito de su labor (A/CN.9/761, párr. 29);

d) Se debe mantener en la definición de “documentos transmisibles electrónicos” la frase entre corchetes (véanse los párrafos 29 a 31 *infra*);

e) Se define alternativamente al “tenedor” como la persona a quien se le ha emitido un documento transmisible electrónico o el cesionario de un documento transmisible electrónico sin ninguna referencia al control;

f) Se incluye una definición de “beneficiario”, “obligante”, “parte controladora” (véase el Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo (Nueva York, 2008), las “Reglas de Rotterdam”) o algún otro término, distinto del de “tenedor”, que se refiera a la persona legitimada para exigir el cumplimiento de la obligación;

g) Es apropiado utilizar el término “persona” o “parte” en los proyectos de disposición;

h) Se incluye una definición de “parte obligada” o algún otro término distinto del de “emisor”, que se refiera a la persona que quede obligada al cumplimiento conforme a lo especificado en el documento o instrumento transmisible emitido en papel o el documento transmisible electrónico;

i) Se utiliza la expresión “cumplimiento de la obligación” para referirse en general a la entrega de las mercancías o el pago de una suma de dinero, conforme figura en el artículo 2, párrafo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (Nueva York, 2005) (la “Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas”) (A/CN.9/761, párr. 22);

j) Se utiliza una expresión más corta, “documento transmisible emitido en papel” (en inglés, “*paper-based transferable record*”), en lugar de “documento o instrumento transmisible emitido en papel” (en inglés, “*paper-based transferable document or instrument*”) y se proporcionan ejemplos (letras de cambio, pagarés, cartas de porte, conocimientos de embarque, resguardos de almacén);

k) Se mantiene la definición de “activación” como algo distinto de la emisión (A/CN.9/761, párr. 31);

l) Resultaría apropiado para referirse al cambio de soporte el término “sustitución” empleado en el artículo 10 de las Reglas de Rotterdam o habría que utilizar otros términos (por ejemplo, conversión o reemplazo) (véase el párrafo 44 *infra*);

m) Se utiliza el término “entrega” únicamente en el contexto de la presentación para el cumplimiento (véanse el proyecto de artículo 25 y el párrafo 49 *infra*);

n) Se proporciona una lista no exhaustiva de los servicios que prestará el tercero prestador de servicios (por ejemplo, la emisión, la transmisión, la sustitución y el archivo de los documentos transmisibles electrónicos) y se ofrecen ejemplos de esos prestadores de servicios (por ejemplo, los operadores de registros o los depositarios); y

o) Se conserva la definición de “transmisión” de un documento transmisible electrónico.

“Proyecto de artículo 4. Interpretación

1. En la interpretación de la presente Ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe.

2. Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente Ley y que no estén expresamente resueltas en ella serán dirimidas de conformidad con los principios generales en que ella se inspira.”

Observaciones

9. El objetivo del proyecto de artículo 4 es señalar a la atención de los tribunales y otros organismos que los proyectos de disposición, aunque se hayan promulgado como parte del derecho interno, se han de interpretar teniendo en cuenta su origen internacional, a fin de facilitar la interpretación uniforme en los distintos países. La mayoría de los textos de la CNUDMI, como la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (artículo 3) y la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas (artículo 5), incluyen una disposición parecida, que está inspirada en el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 1980). El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si se conserva el proyecto de artículo 4 y si se mantiene, quizás desee debatir sobre los principios generales en que deberían basarse los proyectos de disposición. Por ejemplo, en la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico figura una lista no exhaustiva de principios generales, como facilitar el comercio electrónico en el interior y más allá de las fronteras nacionales, fomentar y estimular la aplicación de nuevas tecnologías de la información y apoyar las prácticas comerciales.

“Proyecto de artículo 5. Autonomía de las partes

Será posible apartarse de las disposiciones de la presente Ley o sus efectos podrán ser modificados mediante acuerdo.”

Observaciones

10. Si bien aparecen disposiciones similares al proyecto de artículo 5 en textos de la CNUDMI relativos al comercio electrónico (artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico y artículo 3 de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas), el Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si el proyecto de artículo 5 es adecuado para los proyectos de disposición relativos al empleo de documentos transmisibles electrónicos, en el que generalmente intervienen terceros. El Grupo de Trabajo tal vez desee también examinar las cuestiones relacionadas con la protección de terceros en ese contexto.

“Proyecto de artículo 6. Requisitos de información

Nada de lo dispuesto en la presente Ley afectará a la aplicación de norma jurídica alguna en virtud de la cual las partes deban revelar su identidad, la ubicación de su establecimiento u otros datos, ni eximirá de consecuencias jurídicas a una parte que haya hecho a este respecto declaraciones inexactas, incompletas o falsas.”

Observaciones

11. El proyecto de artículo 6 es parecido al artículo 7 de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas en el que se recuerda a las partes la necesidad de cumplir las posibles obligaciones de revelar datos que imponga el derecho interno (Nota explicativa sobre la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas, párrs. 122 a 128).

B. Utilización de documentos transmisibles electrónicos***“Proyecto de artículo 7. Reconocimiento jurídico de un documento transmisible electrónico***

No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza ejecutoria a un documento transmisible electrónico por la sola razón de que esté en un soporte electrónico.”

“Proyecto de artículo 8. Constancia por escrito

Cuando la ley requiera que [la información] [una comunicación] conste por escrito o prevea consecuencias si no consta por escrito, ese requisito se dará por cumplido respecto del empleo de un documento electrónico si la comunicación electrónica contiene información accesible para su ulterior consulta.”

“Proyecto de artículo 9. Firma

Cuando la ley requiera que [un documento o instrumento emitido en papel] [una comunicación] sea [firmado] [firmada] por una persona, o prevea consecuencias en el caso de que no se firme, ese requisito se dará por cumplido respecto del empleo de un documento transmisible electrónico:

- a) Si se utiliza un método para identificar a esa persona y para indicar la voluntad que tiene esa persona respecto de la información consignada en [el documento transmisible electrónico] [la comunicación]; y
- b) Si el método empleado:
 - i) O bien es tan fiable como sea apropiado para los fines para los que se generó [el documento transmisible electrónico] [la comunicación], atendidas todas las circunstancias del caso, inclusive todo acuerdo aplicable; o
 - ii) Se ha demostrado en la práctica que, por sí solo o con el respaldo de otras pruebas, dicho método ha cumplido las funciones enunciadas en el apartado a) *supra*.”

Observaciones

12. En los proyectos de artículo 8 y 9, que están basados en los artículos 6 y 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico y el artículo 9 de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas (párrafos 2 y 3), se establecen normas mínimas sobre los requisitos de forma que pueden existir en “la ley”, por la que se entiende cualquier norma jurídica que regule los documentos o instrumentos transmisibles emitidos en papel. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si esos proyectos de artículo deberían aplicarse con carácter general a esos requisitos de la ley.

13. Como se ha mencionado (véase el párrafo 5 *supra*), puede haber otros requisitos de forma que existan solo en el contexto del papel. El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si bastaría con el proyecto de artículo 8 para ocuparse de esos casos o si sería necesario preparar disposiciones adicionales.

“Proyecto de artículo 10. Posesión

Cuando la ley requiera la posesión de un documento o instrumento transmisible emitido en papel o prevea consecuencias si se carece de posesión, ese requisito se dará por cumplido mediante el control de un documento transmisible electrónico de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto de artículo 17.”

“Proyecto de artículo 11. Entrega [y endoso]

Cuando la ley requiera la entrega [y endoso] de los documentos o instrumentos transmisibles emitidos en papel o prevea consecuencias en el caso de que no haya entrega [y endoso], ese requisito se dará por cumplido con el traspaso del control de un documento transmisible electrónico de acuerdo con lo dispuesto en el proyecto de artículo 19.”

Observaciones

14. El proyecto de artículo 10 refleja el acuerdo del Grupo de Trabajo de que el equivalente funcional de la posesión se logra mediante el control (A/CN.9/761, párrs. 24 y 25). En el proyecto de artículo 11 se indica que los requisitos de entrega y endoso que existen en la legislación que regula los documentos o instrumentos emitidos en papel se dan por cumplidos mediante el traspaso del control (A/CN.9/761, párr. 50). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si en el

proyecto de artículo 11 se debe mantener la referencia al endoso, ya que este puede no ser siempre necesario (por ejemplo, en los instrumentos emitidos al portador). Además, generalmente el endoso se hará por escrito y con una firma y podría bastar con los proyectos de artículo 8 y 9 para los requisitos de ambas cosas.

“Proyecto de artículo 12. Original

1. Cuando la ley requiera que un documento o instrumento transmisible emitido en papel se proporcione o conserve en su forma original, o prevea consecuencias en el caso de que eso no se cumpla, ese requisito se dará por cumplido respecto del empleo de un documento transmisible electrónico:

a) Si existe alguna garantía fiable de la integridad de la información que contiene el documento transmisible electrónico a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva; y

b) Si, en los casos en que se exija proporcionar la información que contiene el documento transmisible electrónico, esta puede exhibirse a la persona a la que se ha de proporcionar.

2. A los efectos del párrafo 1 a):

a) Los criterios para evaluar la integridad de la información consistirán en determinar si se ha mantenido completa y sin alteraciones que no sean la adición de algún cambio sobrevenido durante el ciclo vital del documento transmisible electrónico; y

b) El grado de fiabilidad requerido se determinará teniendo en cuenta la finalidad para la que se generó la información, así como todas las circunstancias del caso.”

Observaciones

15. En el proyecto de artículo 12 se establecen los requisitos de forma mínimos que debe cumplir un documento transmisible electrónico para ser considerado el equivalente funcional de un original. Es parecido al artículo 8 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico y al artículo 9, párrafo 4 de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas. El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si mantiene esa disposición.

16. El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que el concepto de “original” utilizado habitualmente en el contexto de los documentos transmisibles electrónicos puede ser diferente. Por ello, tal vez sea necesario distinguir entre el requisito de que un documento transmisible electrónico se proporcione o conserve en su forma original y el requisito de que sea singular. Por ello, el Grupo de Trabajo tal vez desee debatir el proyecto de artículo 12 en conexión con los proyectos de artículo siguientes, relativos a la singularidad y la integridad.

17. El artículo 12 de la Ley por la que se establece un marco jurídico para la tecnología de la información (RSQ, c C-1.1) de Quebec puede también arrojar luz². Dice lo siguiente: “Un documento basado en la tecnología puede cumplir las

² El texto completo de la Ley se puede consultar en la dirección siguiente:
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_1_1/C1_1_A.html.

funciones de un original. A ese fin, debe garantizarse la integridad del documento y, cuando la función que se pretende sea demostrar: 1) que el documento es el documento fuente del cual se hacen las copias, deben conservarse los componentes del documento fuente de modo que se puedan utilizar posteriormente como referencia; 2) que el documento es singular, sus componentes o su soporte deben estar estructurados mediante un proceso que haga posible verificar que el documento es singular, especialmente mediante la inclusión de un componente exclusivo o distintivo o la exclusión de cualquier forma de reproducción; 3) que el documento es la primera forma de un documento vinculado a una persona, sus componentes o su soporte deben estar estructurados mediante un proceso que haga posible verificar que el documento es singular, identificar a la persona con la que el documento está vinculado y mantener el vínculo a lo largo de todo el ciclo vital del documento.”

“Proyecto de artículo 13. Singularidad de un documento transmisible electrónico

1. Se utilizará un método fiable para hacer singular un documento transmisible electrónico [e impedir la circulación de múltiples documentos relativos a la misma obligación de cumplimiento] [y dar derecho a un único tenedor a exigir el cumplimiento de la obligación].
2. Un método cumple lo dispuesto en el párrafo 1:
 - a) Si garantiza que el documento transmisible electrónico no puede ser reproducido; o
 - b) Si designa un ejemplar fehaciente del documento transmisible electrónico de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto de artículo 17.”

Observaciones

18. El proyecto de artículo 13 refleja el debate mantenido en el Grupo de Trabajo, en el que se acordó que la singularidad debía tener por objetivo dar derecho a exigir el cumplimiento de la obligación a un único tenedor del documento transmisible electrónico (A/CN.9/761, párrs. 33 a 37 y A/CN.9/WG.IV/WP.118, párrs. 39 a 50). El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si se incluye en el párrafo 1 lo que figura entre corchetes.

“Proyecto de artículo 14. Integridad de un documento transmisible electrónico

1. Se utilizará un método fiable para garantizar que el documento transmisible electrónico conserva su integridad desde el momento en que se emitió por primera vez.
2. A los efectos del párrafo 1:
 - a) Los criterios para evaluar la integridad de la información que figura en el documento transmisible electrónico consistirán en determinar si se ha mantenido completa y sin alteraciones que no sean [la adición de algún cambio] sobrevenido a lo largo de todo el ciclo vital del documento transmisible electrónico; y

b) El grado de fiabilidad requerido se determinará teniendo en cuenta la finalidad para la que se generó la información que figura en el documento transmisible electrónico, así como todas las circunstancias del caso.”

Observaciones

19. A reserva de su debate sobre el proyecto de artículo 12, el Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si se mantiene el proyecto de artículo 14.

“Proyecto de artículo 15. Consentimiento para utilizar un documento transmisible electrónico

1. Nada de lo dispuesto en la presente Ley hará que una persona esté obligada a utilizar un documento transmisible electrónico.

[2. El empleo de un documento transmisible electrónico exige el consentimiento de las partes conforme a lo dispuesto en los proyectos de artículo 16, 19, 22, 23 y 24.]

3. El consentimiento de una persona para utilizar un documento electrónico podrá deducirse de su conducta.”

Observaciones

20. El proyecto de artículo 15 se basa en el artículo 8, párrafo 2 de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas. El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si se debe mantener en los proyectos de disposición el párrafo 2, en el que se establece un requisito general para el consentimiento de las partes.

“Proyecto de artículo 16. Emisión de un documento transmisible electrónico

1. La emisión de un documento transmisible electrónico requerirá el consentimiento del emisor y el primer tenedor para utilizar un soporte electrónico.

2. Para la emisión de un documento transmisible electrónico se exigirá la misma información que se exige para emitir un documento o instrumento transmisible emitido en papel.

3. Al emitirse, un documento transmisible electrónico podrá incluir información adicional, como el consentimiento conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, e información para identificar singularmente el documento transmisible electrónico.

4. [A reserva de lo dispuesto en cualquier norma jurídica que regule la emisión de un documento o instrumento transmisible emitido en papel,] un documento transmisible electrónico podrá ser emitido al portador.

5. Un documento transmisible electrónico se considera emitido cuando el primer tenedor [establece] [es capaz de ejercer] el control del documento de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto de artículo 17.

6. Una vez emitido, un documento transmisible electrónico estará sujeto a control hasta que pierda su validez o eficacia.

7. Cuando la ley requiera la emisión de más de un original de un documento o instrumento transmisible emitido en papel, se dará por cumplido ese

requisito si [existe un solo ejemplar fehaciente del documento transmisible electrónico] [el primer tenedor establece el control] de acuerdo con el procedimiento enunciado en el proyecto de artículo 17.”

Observaciones

21. En el párrafo 1 del proyecto de artículo 16 se indica que las partes que intervienen en la emisión de un documento transmisible electrónico necesitarán acordar la utilización de un soporte electrónico (A/CN.9/761, párr. 32). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar cómo operará este párrafo cuando el documento transmisible electrónico se emita al portador conforme a lo mencionado en el párrafo 4.

22. El párrafo 2 es un recordatorio de que la legislación que regula los documentos o instrumentos transmisibles emitidos en papel se aplica también a los documentos transmisibles electrónicos (véase también el proyecto de artículo 2). El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si se han de mantener esas disposiciones. Un ejemplo de la información para identificar singularmente el documento transmisible electrónico que se menciona en el párrafo 3 podría ser un número de identificación asignado al documento (A/CN.9/761, párr. 32).

23. En el párrafo 4 se refleja el acuerdo del Grupo de Trabajo de que los proyectos de disposición deberían permitir el empleo de documentos transmisibles electrónicos emitidos al portador (A/CN.9/761, párr. 26). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si esa posibilidad se debe enunciar expresamente en los proyectos de disposición.

24. El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si se mantiene el párrafo 5, que trata de cuándo se considera emitido el documento. El Grupo de Trabajo tal vez desee también sopesar si sería conveniente una disposición similar sobre el lugar de la emisión (por ejemplo, “un documento transmisible electrónico se considera emitido en el lugar del establecimiento del emisor”).

25. Con respecto al párrafo 7, el Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si estaría mejor ubicado en el proyecto de artículo 12 (A/CN.9/761, párr. 36).

“Proyecto de artículo 17. Control

1. Una persona ejerce el control de un documento transmisible electrónico si un método utilizado para probar la transmisión de derechos sobre el documento establece fehacientemente que esa persona es aquella en beneficio de la cual se ha emitido o transferido.

2. Un método cumple los requisitos del párrafo 1 y se considera que una persona ejerce el control de un documento transmisible electrónico si el documento se emite y transfiere de tal manera que:

a) Exista del documento transmisible electrónico un solo ejemplar fehaciente que sea singular, identificable e inalterable, salvo lo dispuesto en el proyecto de artículo 20;

b) El ejemplar fehaciente identifique a la persona que afirma tener control como: i) la persona a la que se emitió el documento; o ii) la persona a la cual se haya efectuado la transmisión más reciente del documento transmisible electrónico;

- c) El ejemplar fehaciente se comuniquen a la persona que afirma ejercer control y sea mantenido por ella;
- d) Se mantenga la singularidad e integridad del ejemplar fehaciente; y
- e) [Cada copia del ejemplar fehaciente y cualquier copia de otra copia sean fácilmente identificables como copias que no son el ejemplar fehaciente] [el ejemplar fehaciente sea fácilmente identificable como tal].”

Observaciones

26. El proyecto de artículo 17 fue preparado tomando como base el artículo 7-106 (Control del título electrónico de propiedad) del Código de Comercio Uniforme de los Estados Unidos de América, con cambios menores. El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si ese planteamiento sería adecuado para su labor.

27. Los apartados a) y d) del párrafo 2 deben analizarse en conexión con los artículos 13 y 14, relativos a la singularidad e integridad de un documento transmisible electrónico. El apartado b) debe ser interpretado en el sentido de que en el ejemplar fehaciente se identificará a la persona que afirma tener el control, pero no se revelará necesariamente la identidad (el nombre) de esa persona. Por ello, seguirá siendo posible identificar al tenedor de un documento transmisible electrónico emitido al portador.

28. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si el momento en que una persona establece o es capaz de ejercer el control (por ejemplo, en el proyecto de artículo 16, párrafo 5) es cuando se comunica el ejemplar fehaciente a la persona que afirma tener el control.

“Proyecto de artículo 18. Tenedor

1. Quien tenga el control del documento transmisible electrónico de acuerdo con artículo 17 será su tenedor.
2. Un tenedor está legitimado para: ... ”

Observaciones

29. El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si merece la pena mantener el proyecto de artículo 18 o si basta con contar con la definición de tenedor que figura en el proyecto de artículo 3. Un tenedor de un documento transmisible electrónico solo tendría el control *de facto* del documento. Si el tenedor es el tenedor legítimo y los derechos sustantivos del tenedor serían cuestiones que corresponderían al derecho sustantivo. El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si en el párrafo 2 se debería presentar una lista no exhaustiva de derechos del tenedor (si es que tiene alguno), derivados del control *de facto* del documento transmisible electrónico.

30. En ese contexto, el Grupo de Trabajo tal vez desee también remitirse al capítulo 10 de las Reglas de Rotterdam, que se refiere a los derechos de la parte controladora³. En las Reglas de Rotterdam se utilizan los términos “derecho de

³ Figuran a continuación extractos de las Reglas de Rotterdam:

“Artículo 1. Definiciones
[...]

control” y “parte controladora”; todos ellos se refieren a derechos sustantivos del tenedor de un documento electrónico de transporte negociable. Cabe señalar que en las Reglas de Rotterdam, “parte controladora” se refiere a la parte que tiene el derecho de control. Por ello, en el artículo 51, párrafo 4 de las Reglas de Rotterdam se dispone que el tenedor *de facto* del documento electrónico de transporte negociable es la parte controladora, que puede ejercitar el derecho de control estipulado en el artículo 50.

31. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo tal vez desee confirmar que en los proyectos de disposición se entenderá que el tenedor de un documento transmisible electrónico será la persona que ejerza el control *de facto* del documento. Si el tenedor está legitimado para exigir el cumplimiento sería una cuestión de derecho sustantivo, y en los proyectos de disposición no se dotaría al tenedor de ese derecho (véase el párrafo 8 d) *supra*).

“Proyecto de artículo 19. Traspaso del control de un documento transmisible electrónico

1. Un tenedor de un documento transmisible electrónico podrá transmitir el documento transmisible electrónico traspasando el control del documento al cesionario.
2. [A reserva de lo dispuesto en cualquier norma jurídica que regule la transmisión de un documento o instrumento transmisible emitido en papel,] un documento transmisible electrónico emitido al portador podrá ser transmitido a una persona designada y viceversa.
3. [El traspaso de un documento transmisible electrónico es efectivo] [Un documento transmisible electrónico se considera transmitido] cuando el cesionario obtiene [establece] [es capaz de ejercer] el control del documento

-
13. Por “parte controladora” se entenderá la persona que con arreglo al artículo 51 esté legitimada para el ejercicio del derecho de control.

Artículo 50. Ejercicio y contenido del derecho de control

1. El derecho de control solo podrá ser ejercitado por la parte controladora y comprenderá únicamente:

- a) El derecho a dar o modificar instrucciones relativas a las mercancías que no constituyan una modificación del contrato de transporte;
- b) El derecho a obtener la entrega de las mercancías ...
- c) El derecho a sustituir al destinatario por alguna otra persona, incluida la propia parte controladora.

2. El derecho de control existe durante todo el período de responsabilidad del porteador delimitado conforme a lo previsto en el artículo 12, y se extingue cuando dicho período finaliza.

Artículo 51. Identidad de la parte controladora y transmisión del derecho de control

[...]

4. Cuando se haya emitido un documento electrónico de transporte negociable:

- a) El tenedor será la parte controladora;
- b) El tenedor podrá transmitir el derecho de control mediante la transmisión del documento electrónico de transporte negociable a otra persona efectuada por los procedimientos indicados en el párrafo 1 del artículo 9; y
- c) Para ejercitar el derecho de control, el tenedor deberá probar su condición de tal por los procedimientos indicados en el párrafo 1 del artículo 9.”

transmisble electrónico de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17.

4. Se considera que el cesionario de un documento transmisble electrónico ha consentido en que se utilice el soporte electrónico.

5. Al transmitirse, se incluirá en el documento transmisble electrónico una declaración en la que se indique la transmisión.”

Observaciones

32. El Grupo de Trabajo acordó que se preparasen reglas sobre el traspaso del control (A/CN.9/761, párrs. 50 a 58). Si bien se señaló que el traspaso del control se lograría mediante la modificación del documento transmisble electrónico (A/CN.9/761, párr. 49), el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si el proyecto de artículo 19 no debería ocuparse del procedimiento para el traspaso del control como algo independiente de las modificaciones.

33. El párrafo 2 se redactó para reflejar el análisis del Grupo de Trabajo de que el traspaso del control debería permitir cambios en el modo de transmisión al portador, si el documento se había emitido a una persona designada, y a una persona designada, si el documento se había emitido al portador (A/CN.9/761, párr. 55). El párrafo 3 trata de cuándo tiene lugar el traspaso del control (A/CN.9/761, párr. 56). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si se debería preparar una regla más específica del estilo del artículo 10 de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas.

34. En cuanto al párrafo 4, el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si se debería exigir expresamente el consentimiento del cesionario para que se utilice el soporte electrónico o si se puede deducir (proyecto de artículo 15, párrafo 3).

35. El Grupo de Trabajo tal vez desee seguir debatiendo sobre la necesidad de incluir disposiciones sobre las circunstancias en que una transmisión no surte efectos y la transmisión de derechos parciales sobre el documento transmisble electrónico.

“Proyecto de artículo 20. Modificación de un documento transmisble electrónico

1. Se establecerá un procedimiento fiable para la modificación de un documento transmisble electrónico, que se ocupará también de las modificaciones no autorizadas.

2. Cuando la ley requiera que se haya de notificar la modificación de un documento o instrumento en papel a las partes a las que les afecte, se aplicará la misma norma a la modificación de un documento transmisble electrónico.

3. La modificación de un documento transmisble electrónico [a efectos distintos del traspaso del control] surte efectos cuando la información modificada se refleja en el ejemplar fehaciente.

4. Al efectuar la modificación, se incluirá en el documento transmisble electrónico una declaración en la que se indique que ha tenido lugar una modificación.

5. Una modificación de un documento transmisible electrónico habrá de ser fácilmente identificable como autorizada.”

Observaciones

36. El Grupo de Trabajo acordó que los proyectos de disposición reconociesen la necesidad de ocuparse de las modificaciones y su eficacia, mientras que la cuestión de establecer qué parte podría efectuar las modificaciones y en qué circunstancias debía dejarse al derecho sustantivo (A/CN.9/761, párr. 49). Como se ha mencionado, el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si se debería lograr la transmisión de un documento transmisible electrónico mediante su modificación (véase el párrafo 32 *supra*).

37. En el proyecto de artículo 20 no se incluye un párrafo sobre quién tiene derecho a introducir modificaciones y se deja la cuestión al derecho sustantivo. Sin embargo, el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si debe haber circunstancias en las que el tenedor del documento transmisible electrónico pueda modificarlo unilateralmente.

38. En el párrafo 2 se confirma que se aplicarán a los documentos transmisibles electrónicos los mismos requisitos de notificación que a los documentos o instrumentos emitidos en papel (A/CN.9/761, párr. 47) y el párrafo 3 se ocupa de cuándo surte efectos la modificación.

39. Con respecto al párrafo 4, el Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si se debe incluir esa declaración en el documento transmisible electrónico y, en ese caso, qué otra información debería incluirse (por ejemplo, la identidad de la persona que solicita la modificación o cuándo se efectúa la solicitud). Puesto que en los presentes proyectos de disposición se prevé la inclusión de otros tipos de declaraciones (por ejemplo, en los proyectos de artículo 22, 23, 24 y 26), también será necesario analizar si esas declaraciones deben ser tratadas como modificaciones.

“Proyecto de artículo 21. Error en la información que figura en un documento transmisible electrónico

Con respecto al empleo de un documento transmisible electrónico, se establecerá un procedimiento fiable para corregir los errores producidos al introducir los datos.”

Observaciones

40. El proyecto de artículo 21 refleja el debate mantenido por el Grupo de Trabajo sobre los errores al introducir los datos en el entorno electrónico (A/CN.9/761, párrs. 59 a 62). Si bien se podría optar por la posibilidad de introducir una norma similar al artículo 14 de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas, sería difícil extraer de él una regla que se pudiese aplicar a diversos sistemas y tecnologías. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si basta con el proyecto de artículo 21.

“Proyecto de artículo 22. División de un documento transmisible electrónico

Si un documento transmisible electrónico ha sido emitido y el tenedor y [el emisor/la parte obligada] acuerdan dividirlo en dos o más documentos transmisibles electrónicos:

a) El tenedor [entregará] [presentará para su división] el documento transmisible electrónico [al emisor/a la parte obligada];

b) Los documentos transmisibles electrónicos recién divididos se emitirán de acuerdo con lo dispuesto en el proyecto de artículo 16 e incluirán: i) una declaración de que ha tenido lugar la división; ii) la fecha de la división; y (iii) información para identificar el documento transmisible electrónico original y otro documento o documentos transmisibles electrónicos recién divididos; y

c) Una vez producida la división, el documento transmisible electrónico original quedará privado de su eficacia o validez e incluirá: i) una declaración de que ha tenido lugar la división; ii) la fecha de la división; y iii) información para identificar los documentos transmisibles electrónicos recién divididos.”

“Proyecto de artículo 23. Combinación de documentos transmisibles electrónicos

Si el tenedor de dos o más documentos transmisibles electrónicos, [cuyo emisor/cuya parte obligada] es [el mismo/la misma], acuerda con [el emisor/la parte obligada] combinar los documentos transmisibles electrónicos en un único documento transmisible electrónico:

a) El tenedor [entregará] [presentará para su combinación] los documentos transmisibles electrónicos [al emisor/a la parte obligada];

b) El documento transmisible electrónico recién combinado será emitido de acuerdo con lo dispuesto en el proyecto de artículo 16 e incluirá: i) una declaración de que ha tenido lugar la combinación; ii) la fecha de la combinación; y iii) información para identificar los documentos transmisibles electrónicos originales;

c) Una vez producida la combinación, los documentos transmisibles electrónicos originales quedarán privados de su eficacia o validez e incluirán: i) una declaración de que ha tenido lugar la combinación; ii) la fecha de la combinación; y iii) información para identificar el documento transmisible electrónico recién combinado.”

Observaciones

41. Los proyectos de artículo 22 y 23 se prepararon tomando como base el artículo 10 de las Reglas de Rotterdam, que se refiere a la sustitución, de resultados del debate mantenido en el Grupo de Trabajo acerca de la división y la combinación de los documentos transmisibles electrónicos (A/CN.9/761, párrs. 66 y 67). El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si el procedimiento que se presenta en esos proyectos de artículo es una cuestión de derecho sustantivo y en ese caso, si en los proyectos de disposición se debe indicar únicamente la necesidad de un procedimiento para la división y combinación de los documentos transmisibles electrónicos.

42. El Grupo de Trabajo tal vez desee también analizar si en los proyectos de artículo habría que tener en cuenta la posibilidad de que en el proceso de división o combinación intervenga un documento o instrumento en papel o si para esa circunstancia bastarían los presentes proyectos de artículo en conjunción con el proyecto de artículo 24, relativo a la sustitución.

43. El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota también de que en los proyectos de artículo 22 y 23 se emplean los términos “documento transmisible electrónico original” para referirse al documento transmisible electrónico que queda privado de su eficacia o validez debido a la división o combinación. Para evitar confusiones, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la posibilidad de utilizar algún otro término (por ejemplo, sustituido, inicial o preexistente).

“Proyecto de artículo 24. Sustitución

1. Si se ha emitido un documento o instrumento transmisible emitido en papel y el tenedor y [el emisor/la parte obligada] acuerdan sustituir ese documento o instrumento por un documento transmisible electrónico:

a) El tenedor [entregará] [presentará para que sea sustituido] el documento o instrumento transmisible emitido en papel, o todos ellos si se ha emitido más de uno, [al emisor/a la parte obligada];

b) [El emisor/La parte obligada] deberá emitir al tenedor, en lugar del documento o instrumento transmisible emitido en papel, un documento transmisible electrónico de acuerdo con lo dispuesto en el proyecto de artículo 16 que incluirá una declaración de que ese documento sustituyó al documento o instrumento transmisible emitido en papel; y

c) El documento o instrumento transmisible emitido en papel quedará privado de su eficacia o validez.

2. Si se ha emitido un documento transmisible electrónico y el tenedor y [el emisor/la parte obligada] acuerdan sustituir ese documento transmisible electrónico por un documento o instrumento en papel:

a) El tenedor [entregará] [presentará para que sea sustituido] el documento transmisible electrónico [al emisor/a la parte obligada];

b) [El emisor/La parte obligada] deberá emitir al tenedor, en lugar del documento transmisible electrónico, un documento o instrumento en papel que incluya toda la información que figura en el documento transmisible electrónico y una declaración de que ese documento sustituyó al documento transmisible electrónico; y

c) El documento transmisible electrónico quedará privado de su eficacia o validez.

3. La sustitución de un documento o instrumento transmisible emitido en papel o un documento transmisible electrónico deberá observar ciertos procedimientos que permitan volverlo a emitir en [la forma] [el soporte] original.”

Observaciones

44. De resultas del debate mantenido por el Grupo de Trabajo (A/CN.9/761, párrs. 72 a 77), el proyecto de artículo 24 es parecido al artículo 10 de las Reglas de Rotterdam, que se refiere a la sustitución. El Grupo de Trabajo tal vez desee adoptar primero una decisión sobre si se utilizan los términos “conversión/convertir” o “sustitución/sustituir”, que se referirían al cambio de soporte manteniendo intactos el efecto jurídico y la información incluidos en el documento o instrumento.

45. El Grupo de Trabajo necesitaría además analizar qué partes deberían dar su consentimiento o participar de alguna otra manera en la sustitución (A/CN.9/761, párr. 76) o si esta es una cuestión que correspondería al derecho sustantivo.

46. El párrafo 3 del proyecto de artículo 24 se preparó para el caso en que el documento sustituido necesite ser restaurado, como cuando no se hubiera emitido efectivamente el nuevo documento que había de sustituirlo o dicho documento se hubiera perdido (A/CN.9/761, párr. 76). El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si se necesitaría también una cláusula sobre restauración parecida a esa para los procedimientos relacionados con la división y la combinación.

“Proyecto de artículo 25. [Entrega] [Presentación para el cumplimiento]”

Cuando la ley requiera la [entrega] [presentación para el cumplimiento] de un documento o instrumento transmisible emitido en papel o prevea consecuencias para la falta de [entrega] [presentación para el cumplimiento], ese requisito se dará por cumplido cuando el tenedor del documento transmisible electrónico demuestre su condición de tal de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto de artículo 17.”

Observaciones

47. Se apuntó que en el entorno electrónico, la presentación para el cumplimiento planteaba problemas prácticos importantes debido a la lejanía y la posible falta de familiaridad entre las partes. El Grupo de Trabajo convino en que se preparase una norma dirigida a lograr el equivalente funcional de la entrega física de los documentos en papel (A/CN.9/761, párrs. 70 y 71).

48. En determinados casos, la legislación que regula los documentos o instrumentos en papel puede exigir la entrega del documento o instrumento para su cumplimiento. El objetivo del proyecto de artículo 25 es lograr el equivalente funcional de la entrega utilizando un lenguaje similar al del artículo 47, párrafo 1, apartado a) ii) de las Reglas de Rotterdam. El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si se debe mantener esa disposición o si la cuestión se podría tratar en el marco del proyecto de artículo 11, relativo a la entrega.

49. El Grupo de Trabajo tal vez desee seguir analizando si el término “entrega” puede interpretarse en el sentido de que engloba la presentación para la división, la combinación, la sustitución y el cumplimiento (proyectos de artículo 22 a 25).

“Proyecto de artículo 26. Cumplimiento de la obligación”

1. Se utilizará un método fiable para confirmar que se ha cumplido la obligación. Una vez producida esa confirmación, el documento transmisible electrónico quedará privado de su eficacia o validez.

2. El emisor/La parte obligada pueden negarse a cumplir la obligación:
 - a) Si la persona que afirma tener el control de un documento transmisible electrónico no demuestra que es el tenedor de acuerdo con los procedimientos establecidos en el proyecto de artículo 17;
 - b) Si hay más de una persona que demuestre ser el tenedor; o
 - c) Si ...
3. Cuando [el emisor/la parte obligada] se niega a cumplir la obligación de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2, el tenedor mantendrá el control del documento transmisible electrónico y se incluirá en este una declaración de que [el emisor/la parte obligada] se negó a cumplir la obligación.
4. Cuando la obligación se cumple parcialmente, el documento electrónico se modificará de acuerdo con lo dispuesto en el proyecto de artículo 20 y [se incluirá una declaración de que hubo un cumplimiento parcial].”

Observaciones

50. El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si los párrafos del proyecto de artículo 26 tratan de cuestiones de derecho sustantivo y no deberían estar incluidos en los proyectos de disposición.
51. El párrafo 3 trata de la negativa del emisor/la parte obligada a cumplir la obligación y el párrafo 4 se ocupa, mediante la modificación del documento transmisible electrónico, de la cuestión del cumplimiento parcial (A/CN.9/761, párr. 70). El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si el proyecto de artículo debería ocuparse también de la negativa del tenedor a recibir o aceptar el cumplimiento de la obligación.

“Proyecto de artículo 27. Cancelación de un documento transmisible electrónico

1. Cuando un documento transmisible electrónico queda privado de su eficacia o validez de acuerdo con los artículos 22, 23, 24 y 26 será cancelado y se establecerá un método para impedir que siga circulando.
2. Cuando la ley requiera que se incluya en el documento o instrumento transmisible emitido en papel una declaración que indique su cancelación, ese requisito se dará por cumplido incluyendo una declaración en el documento transmisible electrónico de que ha sido cancelado.”

Observaciones

52. El proyecto de artículo 27 trata de la cancelación de un documento transmisible electrónico y no de la cancelación de la obligación básica, que es una cuestión de derecho sustantivo (A/CN.9/761, párr. 78). El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si es necesario distinguir entre la cancelación de un documento transmisible electrónico al sustituirlo (proyecto de artículo 24) y la cancelación una vez cumplida la obligación (proyecto de artículo 26) (A/CN.9/761, párr. 75).
53. En el párrafo 2 se calca el requisito de incluir en los documentos o instrumentos en papel anotaciones en las que se indique la cancelación.

54. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la posibilidad de insertar un párrafo en el proyecto de artículo 27 en el que se exija notificar la cancelación a las partes correspondientes.

“Proyecto de artículo 28. Garantía real sobre un documento transmisible electrónico

Puede constituirse una garantía real sobre un documento transmisible electrónico de acuerdo con la legislación aplicable sobre las operaciones garantizadas.”

Observaciones

55. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si sería más adecuado para reflejar su debate el texto siguiente (A/CN.9/761, párrs. 63 a 65): “Se establecerá un procedimiento fiable para permitir [la constitución de una garantía real sobre un documento transmisible electrónico] [el empleo de documentos transmisibles electrónicos a efectos de una garantía real].”

56. El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que en la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (2007) se define la garantía real como un derecho de propiedad sobre bienes muebles que se constituya mediante un acuerdo y que garantice el pago u otro tipo de cumplimiento de una obligación, independientemente de que las partes lo hayan calificado o no de garantía real.

“Proyecto de artículo 29. Archivo de información en un documento transmisible electrónico

1. Cuando la ley requiera que un documento o instrumento transmisible emitido en papel sea archivado, se dará por cumplido ese requisito archivando un documento transmisible electrónico, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a) La información consignada en su texto es accesible para su ulterior consulta;

b) El documento transmisible electrónico se archiva en el formato en que fue emitido o en un formato que es demostrable que reproduce con exactitud la información consignada en su texto; y

c) Esa información, de haberla, se archiva de un modo que permita identificar al emisor y al tenedor o tenedores del documento transmisible electrónico y la fecha y hora en que fue emitido y traspasado y cuándo queda privado de su eficacia o validez.

2. Los requisitos mencionados en el párrafo 2 podrán ser cumplidos utilizando los servicios de un tercero prestador de servicios, siempre que se cumplan las condiciones estipuladas en ese párrafo.”

Observaciones

57. El proyecto de artículo 29 se ocupa del almacenamiento de información en los documentos transmisibles electrónicos y fue preparando tomando como base el artículo 10 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (A/CN.9/761, párr. 81). El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si se debe aplicar

el mismo requisito a los documentos transmisibles electrónicos que hayan sido divididos o combinados de acuerdo con lo dispuesto en los proyectos de artículo 22 y 23 y a los documentos o instrumentos transmisibles emitidos en papel o documentos transmisibles electrónicos que hayan sido sustituidos de acuerdo con lo dispuesto en el proyecto de artículo 24.

C. Terceros prestadores de servicios

“Proyecto de artículo 30. Funciones de un tercero prestador de servicios

Un tercero prestador de servicios desempeñará las funciones siguientes con respecto al empleo de documentos transmisibles electrónicos:

- a) ...”

“Proyecto de artículo 31. Proceder de un tercero prestador de servicios

1. Cuando un tercero prestador de servicios respalde el empleo de un documento transmisible electrónico, ese tercero prestador de servicios:

- a) Actuará conforme a las declaraciones que haya hecho sobre sus normas y prácticas;
- b) Actuará con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones importantes que haya hecho en relación con el ciclo vital del documento transmisible electrónico son exactas y cabales;
- c) Proporcionará a la parte que confía en el documento transmisible electrónico medios razonablemente accesibles que permitan a esta determinar mediante ese documento:
 - i) La identidad del tercero prestador de servicios;
 - ii) Que el tenedor nombrado en el documento transmisible electrónico tenía bajo su control ese documento en el momento en que se emitió;
 - iii) Que la información que figura en el documento transmisible electrónico era válida en la fecha en que se emitió ese documento;
- d) Proporcionar a la parte que confía en el documento transmisible electrónico medios razonablemente accesibles que, cuando proceda, permitan a esta determinar mediante el documento transmisible electrónico:
 - i) El método utilizado para comprobar la identidad del emisor/la parte obligada y el tenedor;
 - ii) Cualquier limitación de los fines o del valor respecto de los cuales pueda utilizarse el documento transmisible electrónico;
 - iii) Que la información que figura en el documento transmisible electrónico es válida y no está en entredicho;
 - iv) Cualquier limitación del alcance o del grado de responsabilidad que haya establecido el tercero prestador de servicios;
- e) Utilizar, al prestar sus servicios, sistemas, procedimientos y recursos humanos fiables.

2. Serán de cargo del tercero prestador de servicios las consecuencias jurídicas que entrañe el hecho de no haber cumplido los requisitos enunciados en el párrafo 1.”

“Proyecto de artículo 32. Fiabilidad [Requisitos en materia de licencias]

A los efectos del artículo 31, párrafo 1 e) de la presente Ley, para determinar si los sistemas, procedimientos o recursos humanos utilizados por un tercero prestador de servicios son fiables, y en qué medida lo son, podrán tenerse en cuenta los factores siguientes:

- a) Los recursos humanos y financieros, incluida la existencia de activos;
- b) La calidad de los sistemas de equipo y programas informáticos;
- c) Los procedimientos para la tramitación del documento transmisible electrónico;
- d) La disponibilidad de información para las partes allegadas;
- e) La periodicidad y el alcance de la auditoría realizada por un órgano independiente;
- f) La existencia de una declaración del Estado, de un órgano de acreditación o del tercero prestador de servicios respecto del cumplimiento o la existencia de los factores que anteceden; o
- g) Cualesquiera otros factores pertinentes.”

“Proyecto de artículo 33. Responsabilidad del tercero prestador de servicios

1. Un tercero prestador de servicios responderá por cualesquiera daños causados por su negligencia o error en la utilización de documentos transmisibles electrónicos.

2. Un tercero prestador de servicios no responderá por los daños:

- a) Derivados de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias;
- b) Relacionados con el cumplimiento de la obligación; o
- c) Derivados de la negligencia o la violación de su obligación por parte del usuario del servicio.”

Observaciones

58. En su último período de sesiones, el Grupo de Trabajo mantuvo un debate preliminar sobre cuestiones relacionadas con los terceros prestadores de servicios (A/CN.9/761, párrs. 83 a 86). Los proyectos de artículo 30 a 33 se prepararon tomando como base los artículos 9 y 10 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas, que se refieren a los prestadores de servicios de certificación, como un posible criterio.

59. El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si se deben incluir disposiciones sobre los terceros prestadores de servicios y en qué medida. Si se incluyen esas reglas, su objetivo debería ser abarcar a todos los terceros prestadores de servicios, sin referirse a ninguna tecnología ni sistema concretos (A/CN.9/761, párr. 27).

D. Reconocimiento transfronterizo de los documentos transmisibles electrónicos

“Proyecto de artículo 34. Reconocimiento de los documentos transmisibles electrónicos extranjeros

1. Al determinar si un documento transmisible electrónico produce efectos jurídicos, o en qué medida los produce, no se tomará en consideración el lugar en que se haya emitido o en que se haya utilizado.
2. Un documento transmisible electrónico emitido fuera [del Estado promulgante] producirá los mismos efectos jurídicos en [el Estado promulgante] que todo documento transmisible electrónico emitido en [el Estado promulgante] si presenta un grado de fiabilidad sustancialmente equivalente.
3. A efectos de determinar si un documento transmisible electrónico presenta un grado de fiabilidad sustancialmente equivalente para los fines del párrafo 2, se tomarán en consideración las normas internacionales reconocidas y cualquier otro factor pertinente.”

Observaciones

60. En el 45º período de sesiones de la Comisión, celebrado en 2012, se subrayó la necesidad de un régimen internacional que facilitase la utilización transfronteriza de los documentos transmisibles electrónicos⁴. El Grupo de Trabajo reiteró también la importancia de los aspectos transfronterizos del reconocimiento jurídico de los documentos transmisibles electrónicos (A/CN.9/761, párrs. 87 a 89).

61. El artículo 34 se redactó para que fuese parecido al artículo 12 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas. Sin embargo, cabe señalar que en los proyectos de disposición no se menciona el “lugar en que se haya emitido o utilizado el documento transmisible electrónico”.

62. El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si el enfoque adoptado en el proyecto de artículo 34 sería apropiado para tratar de los aspectos transfronterizos. Un enfoque alternativo podría ser adoptar disposiciones sobre el conflicto de leyes similares a las del Convenio destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés a la orden (Ginebra, 7 de junio de 1930).

⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 83*

III. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LÍNEA

A. Informe del Grupo de Trabajo sobre solución de Controversias en Línea sobre la labor realizada en su 26º período de sesiones (Viena, 5 a 9 de noviembre de 2012)

(A/CN.9/762)

[Original: inglés]

Índice

	Párrafos
I. Introducción.	1-4
II. Organización del período de sesiones	5-11
III. Deliberaciones y decisiones.	12
IV. Solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento.	13-81
A. Observaciones generales	13-24
B. Notas sobre el proyecto de reglamento.	25-81
6. Decisión del tercero neutral	25-67
7. Otras disposiciones	68-81
V. Labor futura.	82
Anexo	

I. Introducción

1. En su 43º período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010), la Comisión convino en que se estableciera un Grupo de Trabajo con la misión de ocuparse de la solución de controversias en línea surgidas en operaciones transfronterizas de comercio electrónico, incluidas las operaciones entre empresas y entre empresas y consumidores¹. Se convino también en que la forma de la futura norma jurídica se decidiría una vez que se hubiera examinado con más detalle ese nuevo tema.

2. En su 44º período de sesiones (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011), la Comisión reafirmó el mandato del Grupo de Trabajo III sobre solución en línea de controversias surgidas a raíz de operaciones transfronterizas de comercio electrónico, incluidas las operaciones tanto entre empresas como entre empresas y consumidores². La Comisión decidió que, si bien el Grupo de Trabajo debía tener latitud para interpretar que su mandato abarcaba las operaciones entre consumidores y para elaborar un posible reglamento que las regulase cuando fuera preciso, debería

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), párr. 257.*

² *Ibid., sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 218.*

tener especialmente en cuenta la necesidad de no dejar de lado la legislación de protección del consumidor. La Comisión decidió asimismo que el Grupo de Trabajo, en el cumplimiento de su mandato, debería también considerar concretamente los efectos de sus deliberaciones sobre la protección de los consumidores e informar al respecto a la Comisión en su 45º período de sesiones³.

3. En su 45º período de sesiones (Nueva York, 25 de junio a 6 de julio de 2012), la Comisión reafirmó el mandato del Grupo de Trabajo respecto de las operaciones electrónicas transfronterizas en gran volumen y de poca cuantía, y alentó al Grupo de Trabajo a que prosiguiera su labor de la manera más eficiente posible⁴. Se convino además en que el Grupo de Trabajo debería analizar la manera en que el reglamento respondería a las necesidades de los países en desarrollo y otros países en situaciones posteriores a conflictos, en particular en lo que se refiere a la necesidad de que el proceso conste de una etapa de arbitraje, y posteriormente informar a la Comisión en un futuro período de sesiones acerca de los resultados de dicho análisis; y en que el Grupo de Trabajo debería continuar examinando, en el marco de sus deliberaciones, los efectos del procedimiento de solución de controversias en línea en la protección del consumidor en países en desarrollo y desarrollados y en situaciones posteriores a conflictos⁵.

4. La recopilación más reciente de referencias relativas a la evolución del examen por la Comisión de la labor del Grupo de Trabajo se encuentra en los párrafos 5 a 14 del documento A/CN.9/WG.III/WP.116.

II. Organización del período de sesiones

5. El Grupo de Trabajo III (Solución de Controversias en Línea), integrado por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 26º período de sesiones en Viena del 5 al 9 de noviembre de 2012. Asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Austria, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, China, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Honduras, Israel, Japón, Kenya, México, Pakistán, República Checa, República de Corea, Senegal, Singapur, Tailandia, Turquía, Ucrania y Venezuela (República Bolivariana de).

6. Asistieron también al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Belarús, Bélgica, Chipre, Ecuador, Finlandia, Hungría, Indonesia, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal y República Dominicana.

7. También asistieron al período de sesiones observadores de Palestina y de la Unión Europea.

8. Asistieron, además, observadores de las siguientes organizaciones internacionales:

- a) *Organizaciones intergubernamentales*: Liga de los Estados Árabes;

³ *Ibid.*, párr. 218.

⁴ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 79.

⁵ *Ibid.*, párr. 79.

b) *Organizaciones internacionales no gubernamentales*: Center for International Legal Education (CILE), Construction Industry Arbitration Council (CIAC), Instituto de Derecho y Tecnología (Universidad Masaryk), Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (ILCE), National Center for Technology and Dispute Resolution (NCTDR), New York State Bar Association (NYSBA) y Tribunal de Arbitraje de Madrid.

9. El Grupo de Trabajo eligió la siguiente Mesa:

Presidente: Sr. Agustín MADRID PARRA (España)

Relatora: Sra. Olga KOSTYSHYNA (Ucrania)

10. El Grupo de Trabajo tuvo a su disposición los siguientes documentos:

a) Programa provisional anotado (A/CN.9./WG.III/WP.116);

b) Nota de la Secretaría relativa a la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento (A/CN.9/WG.III/WP.117 y Add.1);

c) Nota de la Secretaría relativa a la solución en línea de controversias surgidas a raíz de operaciones transfronterizas de comercio electrónico: otras cuestiones que deberán examinarse para elaborar un marco global que rijan la solución de controversias en línea (ODR) (A/CN.9/WG.III/WP.113);

d) Propuesta del Gobierno del Canadá sobre los principios aplicables a los proveedores de servicios de solución de controversias en línea y a los terceros neutrales (A/CN.9/WG.III/WP.114); y

e) Nota presentada por el Center for International Legal Education (CILE) relativa al análisis de los principios sustantivos de la demanda y la reparación en la solución de controversias en línea y propuesta para incorporarlos al artículo 4 del proyecto de reglamento (A/CN.9/WG.III/WP.115).

11. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:

1. Apertura del período de sesiones.
2. Elección de la Mesa.
3. Aprobación del programa.
4. Examen de la solución en línea de controversias surgidas en el marco de operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento.
5. Otros asuntos.
6. Aprobación del informe.

III. Deliberaciones y decisiones

12. El Grupo de Trabajo reanudó su labor sobre el tema 4 del programa basándose en las notas preparadas por la Secretaría (A/CN.9/WG.III/WP.117 y su adición; A/CN.9/WG.III/WP.113; A/CN.9/WG.III/WP.114; y A/CN.9/WG.III/WP.115). Las

deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo respecto de este tema se recogen en el capítulo IV.

IV. Solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento

A. Observaciones generales

13. Al comienzo del 26º período de sesiones del Grupo de Trabajo, se propuso hacer una pausa para celebrar consultas oficiosas a fin de tratar de llegar a un acuerdo respecto de una serie de cuestiones fundamentales sobre las que había divergencia de opiniones. Hubo un amplio acuerdo en que esas consultas oficiosas podían resultar útiles para avanzar en el examen general del reglamento.

14. Por la tarde del primer día del período de sesiones, una delegación presentó, en nombre de quienes habían participado en las consultas oficiosas, un breve informe sobre los progresos realizados en ellas. Se dijo que se habían expresado dos puntos de vista principales, a saber: i) el de los países cuya legislación no consideraba vinculantes para los consumidores los acuerdos de arbitraje previos a las controversias, y ii) el de los países que no tenían legislación de ese tipo. Se señaló que la inclusión de una etapa de arbitraje en el reglamento podría resultar problemática en los países en que tales acuerdos no se consideraban vinculantes.

15. Se sugirió que para superar ese obstáculo se podría adoptar un sistema ODR basado en “dos modalidades”, una que incluyera las fases de negociación, arreglo facilitado y arbitraje, y otra que omitiera la fase de arbitraje. Se afirmó que ello podría lograrse preparando cláusulas o disposiciones alternativas que dispusieran que las partes en una operación pudieran acordar usar el reglamento ODR, y asegurando que cada una de las cláusulas previera la aplicación de una “modalidad” distinta. Se dijo que había consenso sobre la necesidad de que el reglamento fuera flexible y permitiera (entre otras cosas) un enfoque con dos modalidades como el que se había propuesto.

16. A ese respecto, se estableció un nexo con el proyecto de artículo 8 1) *bis*, relativo al paso a la etapa de arbitraje cuando las partes no hubieran llegado a acuerdo para solucionar su controversia. Esa cuestión tenía que ver con el requisito existente en algunos países de que el consumidor llegara a un acuerdo posterior a la controversia antes de proceder a la etapa de arbitraje y con el asunto conexo del momento del procedimiento en que se requeriría llegar a ese acuerdo (llamado a veces el “segundo clic”). Se señaló que para avanzar en esa cuestión convendría organizar más consultas oficiosas, a las que se procedió seguidamente con el acuerdo del Grupo de Trabajo.

17. Varias delegaciones señalaron la necesidad de que en el proceso (ODR) hubiera una etapa de arbitraje que llevara a un resultado jurídicamente vinculante, en particular en los países en desarrollo, donde se consideraba que ofrecía a los consumidores, así como a las pequeñas empresas, cierto grado de protección en las operaciones comerciales del que por el momento carecían. Varias otras delegaciones opinaron que a todos los países les interesaba contar con un sistema mundial de solución de controversias eficiente, rápido y eficaz en función del costo y que había

que decidir qué tipo de soluciones resultarían de un sistema como ese. Se aclaró que las consultas oficiosas consistían en sesiones de intercambio de ideas para alcanzar una visión común y que no debía considerarse que las conclusiones a que se llegara en esas sesiones fueran vinculantes para quienes participaran en ellas.

18. Se convino en que las consultas oficiosas, aunque no dieran lugar a un acuerdo oficial, servían para alcanzar un mayor consenso sobre algunas cuestiones, concretamente la de que el reglamento podía incorporar tanto una modalidad ODR que incluyera una fase de arbitraje como una que no incluyera dicha fase. Varias delegaciones consideraron que en toda etapa de arbitraje se debían tener en cuenta las inquietudes respecto de la protección del consumidor expresadas por las delegaciones en cuyas jurisdicciones se preveía que los acuerdos de arbitraje previos a la controversia no eran vinculantes para los consumidores.

19. Se dio por entendido en general que el reglamento ODR debía permitir acuerdos de arbitraje anteriores a una controversia en las jurisdicciones en que la ley, a su vez, permitiera que esos acuerdos fuesen vinculantes para todas las partes. También se convino en que todos compartían la preocupación por la protección de los consumidores, que podía reflejarse de forma diferente en los distintos contextos y sistemas de los distintos países. Se acordó además que el Grupo de Trabajo reanudara su examen del proyecto de reglamento, comenzando por el proyecto de artículo 9, partiendo de la base de que dicho artículo no se aplicaría a la modalidad “sin arbitraje” de cualquier arreglo conciliatorio que pudiera alcanzarse.

20. Respecto del sistema con dos modalidades examinado por el Grupo de Trabajo, se señaló que tal vez no se había tenido suficientemente en cuenta la posibilidad de una tercera modalidad, la de que hubiese una decisión de un tercero neutral que no equivaliera a una decisión arbitral oficial, sino que estuviera sujeta a mecanismos de ejecución privados. Se sostuvo que esa tercera opción no impediría la posibilidad de proceder a un proceso oficial de arbitraje. Se indicó también que la Comisión, en su informe de 2012 (A/67/17), concretamente en el párrafo 79 c), había encomendado expresamente al Grupo de Trabajo el mandato de analizar una opción privada para garantizar la ejecución. El Grupo de Trabajo apoyó esa propuesta.

Propuesta

21. Se presentó un documento cuya finalidad era aclarar las dos modalidades que las delegaciones habían examinado oficiosamente durante la semana y proponer el texto de los artículos pertinentes del reglamento; ese documento, que no fue aprobado oficialmente por el Grupo de Trabajo, y cuya redacción no se examinó durante el período de sesiones, figura como anexo del presente informe. Muchas delegaciones encomiaron el espíritu de cooperación con que se había preparado el documento y se mostraron optimistas de que el enfoque con dos modalidades, que podría dar cabida dentro del grupo a dos perspectivas distintas para la aplicación del reglamento, pudiera servir de base para seguir examinándolo. Sin embargo, se señaló que no debía considerarse que el texto excluyera otras modalidades, en particular si constituían un posible mecanismo de cumplimiento alternativo al arbitraje y si en ellas se proponía una estructura del reglamento que posibilitara la existencia de dicho mecanismo.

22. Además, a modo de aclaración y con respecto a la primera opinión formulada en el documento, se señaló que en él se planteaba también la postura de que el reglamento ODR debía concebirse sin que se previera en él una transición automática a la etapa de arbitraje, en particular en relación con los consumidores en cuyas jurisdicciones se previera que los acuerdos de arbitraje previos a la controversia no eran de carácter vinculante para ellos y que no hubieran acordado después de surgida su controversia someterse a arbitraje en línea.

23. Se señaló que, si bien se había avanzado en la preparación de ese documento, existía el riesgo de que el mercado fuese un mercado dinámico y que su evolución restara actualidad a la labor del Grupo de Trabajo. Se señaló que el grupo que más necesitaba procedimientos ODR eficaces era el de los consumidores, y que uno de los principales objetivos era mantener la sencillez y accesibilidad del reglamento.

24. Otras delegaciones alentaron al Grupo de Trabajo a que en el próximo período de sesiones formulara propuestas de redacción concretas, vinculadas a artículos determinados, que reflejaran la postura jurídica de las respectivas delegaciones, a fin de promover el avance en la preparación del reglamento y aumentar la eficacia de su labor. Se indicó también que el documento podía servir de base para una nueva versión del reglamento para examinarla durante el 27º período de sesiones del Grupo de Trabajo.

B. Notas sobre el proyecto de reglamento

6. Decisión del tercero neutral

Proyecto de artículo 9 ([Emisión de] [Comunicación de] [una decisión] [un laudo])

25. El Grupo de Trabajo examinó el proyecto de artículo 9 que figuraba en el párrafo 44 del documento A/CN.9/WG.III/WP.117/Add.1.

Párrafo 1

“Laudo” frente a “decisión”

26. Varias delegaciones se mostraron partidarias de que se empleara la palabra “laudo” y no la palabra “decisión”, argumentando que “laudo” se correspondía con el lenguaje que se utilizaba en los ordenamientos jurídicos nacionales en referencia al resultado de una controversia sobre una cuestión de fondo, así como con el lenguaje que figuraba en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Se afirmó que ese lenguaje no plantearía problema en el caso de la posible “primera modalidad” expuesta en el párrafo 15.

27. También se argumentó que el empleo de “laudo” supondría un apoyo a la armonización de la terminología jurídica y que esa palabra siempre se había utilizado en el contexto tradicional del arbitraje. Además se afirmó que era importante avanzar en la elaboración del reglamento y que eliminar los corchetes, aunque no significara que se hubiera llegado a una postura definitiva sobre la cuestión, ayudaría al Grupo de Trabajo a progresar en su examen del reglamento.

28. Varias delegaciones fueron partidarias de dejar entre corchetes las palabras “decisión” y “laudo” empleadas en el párrafo 1, hasta que el Grupo de Trabajo

hubiera definido mejor la incorporación de las posibles “dos modalidades” en el reglamento y para reflejar que seguía habiendo opiniones divergentes sobre esas dos palabras. También se afirmó que otros medios de ejecución, como los mecanismos de ejecución privados, podrían requerir soluciones distintas al arbitraje, por lo que sería preferible no limitar por el momento la terminología del párrafo 1.

29. En respuesta a la pregunta de si existía alguna diferencia entre “decisiones” y “laudos”, se dijo que i) existía una diferencia procedimental, pues los laudos se emitían sobre cuestiones de fondo mientras que las decisiones se emitían en relación con cuestiones de procedimiento y con medidas cautelares; y ii) que en el contexto de un arreglo facilitado el resultado no sería ni un laudo ni una decisión, pero en el contexto del arbitraje el resultado sería siempre un “laudo”.

30. Se sugirió que se incluyera en el comentario la aclaración de que i) un “laudo” solo se aplicaría al arbitraje; ii) el reglamento tendría que resolver las cuestiones relativas a la prohibición, vigente en muchas jurisdicciones, de los acuerdos vinculantes previos a una controversia para proceder al arbitraje; y iii) el reglamento reconocería que, además del arbitraje, existiría otra modalidad, como la basada únicamente en la mediación o la basada en una resolución.

Límites temporales

31. El párrafo 1 que figuraba en el párrafo 44 del documento A/CN.9/WG.III/WP.117/Add.1 requería que el tercero neutral emitiera su decisión o laudo en un plazo de siete días calendario, con una posible extensión por otros siete días calendario.

32. Algunas delegaciones opinaron que siete días calendario (más la extensión por siete días, que por el momento figuraba entre corchetes) eran suficientes para que el tercero neutral emitiera una decisión, habida cuenta del poco valor y el elevado volumen de las operaciones objeto de las controversias, y que ese plazo facilitaría una solución de dichas controversias de manera rápida y eficiente en función del costo. Otras delegaciones opinaron que siete días no bastaban, pero no propusieron otra opción que insertar en el texto.

33. Otra propuesta fue que el plazo para la emisión de la decisión o el laudo comenzara a correr el día en que el tercero neutral recibiera la documentación definitiva, en lugar del día en que la hubieran presentado las partes.

34. Se señaló que habían surgido dos posturas claras sobre el párrafo 1: i) algunas delegaciones opinaban que deberían mantenerse los corchetes en el párrafo 1; y ii) otras eran partidarias de suprimir los corchetes, mantener la palabra “laudo” y suprimir la palabra “decisión” en todo el texto.

35. Aunque se apoyó la idea de mantener los corchetes en el párrafo 1, la opinión predominante sobre ese párrafo fue la de que se suprimieran los corchetes, se mantuviera la palabra “laudo” y se suprimiera la palabra “decisión”.

36. Algunas delegaciones solicitaron que se dejara constancia de que objetaban esa conclusión por considerar que era prematura y podía dificultar el examen futuro del párrafo. También se aclaró que el párrafo 1 solo se refería a una posible vía arbitral y que en cualquier caso el Grupo de Trabajo podría volver a examinarlo en una próxima lectura del reglamento.

37. Asimismo, se convino en suprimir todos los demás corchetes del párrafo 1, incluidos los de las palabras “con la posibilidad de una extensión de otros siete (7) días calendario” y los de las palabras “sin dilación”, a fin de conservarlas, y en suprimir además la palabra “rápidamente”.

Párrafo 2

Breve descripción de los motivos

38. Hubo amplio consenso respecto de que debía mantenerse en el párrafo 2 la formulación que exigía una breve descripción de los motivos de la decisión del tercero neutral, entre otras cosas para mantener la coherencia con el párrafo 3 del artículo 34 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 (“Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI”). Por consiguiente, se acordó suprimir los corchetes del párrafo 2.

39. Otra propuesta fue la de incluir el requisito de que el tercero neutral describiera brevemente los motivos de la decisión en documentos complementarios que se prepararían en un futuro período de sesiones, como las Directrices para proveedores de servicios de solución de controversias en línea (ODR) y terceros neutrales.

Lugar de arbitraje e identidad de las partes

40. Varias delegaciones se mostraron partidarias de incluir en el párrafo 2 el requisito de que, además de la fecha, en el laudo emitido en virtud de ese párrafo se especificara también a) el lugar del arbitraje y b) la identidad de las partes en la controversia.

41. En relación con la primera parte de la propuesta, se hizo una distinción entre la determinación del lugar de arbitraje y la indicación de dicho lugar en el laudo. Se convino en que el párrafo 2 era el lugar más apropiado para incluir el último requisito pero no el primero, que debía figurar en otra parte del reglamento.

42. En relación con la segunda parte de la propuesta, no recibió apoyo la sugerencia de que en la disposición se exigiera que el laudo especificara la identidad de las partes, por dos razones: i) era evidente que la identidad de las partes se indicaría en el laudo y no hacía falta incluir un requisito expreso al respecto; y ii) la inclusión de ese requisito sería inusual y resultaría incongruente con los demás textos de la CNUDMI.

43. Por consiguiente, se acordó que el párrafo 2, además de exigir que en el laudo se indicara la fecha de emisión, exigiera que se señalara el lugar de arbitraje, pero se decidió no agregar a ese párrafo ningún requisito expreso de identificar a las partes.

“Por escrito y firmado [firmada] por el tercero neutral”

44. Se consideró que el significado de la palabra “escrito” en el contexto de un procedimiento electrónico era claro, pues existía un proyecto de definición de esa palabra en el proyecto de artículo 2 9) del reglamento, pero que en este no figuraba una definición de la palabra “firma”. El Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría que en el próximo proyecto de reglamento se agregara esa definición, basada en las normas existentes de la CNUDMI en la esfera del comercio electrónico.

Publicación

45. Se propuso que en el reglamento se procurara establecer el requisito de publicar los laudos, previa eliminación de información confidencial como la identidad de las partes. Algunas delegaciones apoyaron esa propuesta, considerando que: i) daría transparencia al sistema ODR y crearía un mecanismo de supervisión, puesto que probablemente no habría revisión judicial; ii) podría resultar educativo presentar al público (incluidos los consumidores) información de ese tipo; y iii) en la esfera del arbitraje se tendía actualmente a promover la transparencia, como se observaba en la labor del Grupo de Trabajo II de la CNUDMI y en los casos de arbitraje en el mundo deportivo. Se señaló que una forma de incluir esa propuesta en el reglamento consistiría en incorporar una disposición por la que se exigiera la publicación “salvo que las partes acordaran otra cosa”.

46. Otras delegaciones se opusieron a la propuesta, argumentando que: i) el arbitraje se basaba, por su propia naturaleza, en la confidencialidad, y las cuestiones de transparencia que afectaban a los procedimientos de arbitraje entre inversionistas y Estados y a los tribunales que conocían de causas antidopaje en el mundo deportivo no eran pertinentes ni comparables a los casos de solución en línea de controversias relativas a operaciones de poco valor; ii) permitir la publicación exigiría todo un conjunto de complejas normas complementarias, entre otras cosas sobre la protección de la información confidencial; iii) el volumen de las controversias sometidas a un procedimiento de solución en línea conforme al reglamento haría impracticable su publicación; y iv) el mecanismo de supervisión mencionado por quienes apoyaban la propuesta podría lograrse mediante la recopilación de estadísticas y datos de los proveedores de servicios ODR.

47. Se convino en seguir examinando la cuestión en un período de sesiones futuro del Grupo de Trabajo y, para facilitar ese examen, en incluir en la próxima versión del reglamento, entre corchetes, una disposición que reflejara el contenido del artículo 34 5) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

Párrafo 3

48. Se hicieron las siguientes propuestas en relación con el párrafo 3: i) suprimir los corchetes del párrafo; y ii) mantener la palabra “laudo” en lugar de la palabra “decisión” a fin de mantener la coherencia con la terminología del proyecto de artículo 9 1). También se sugirió que se mantuviera la frase “sin dilación” en lugar de la palabra “rápidamente” en la segunda oración, a fin de mantener la coherencia con los términos empleados en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. No recibió apoyo la sugerencia de utilizar la palabra “rápidamente” en lugar de las palabras “sin dilación”.

49. Se sugirió también que en el párrafo 2 se dispusiera que el tercero neutral fijara un plazo para que las partes cumplieran el laudo.

50. Se propuso incorporar al reglamento una disposición conforme a la cual el laudo no fuese vinculante para un consumidor cuya participación en el procedimiento ODR se hubiera basado en un acuerdo de arbitraje previo a la controversia invocando el cual se pretendiera privarlo de su derecho a acceder a un tribunal para la solución de la controversia, cuando la ley de la jurisdicción por la que se rigiera el consumidor garantizara ese derecho. Varias delegaciones apoyaron esa propuesta.

51. Se cuestionó la propuesta, o su inclusión en el párrafo 3, por considerarse que no era viable, se refería al acuerdo de arbitraje y no al laudo y atentaba contra el objetivo deseado de preparar un reglamento sencillo. Además, se señaló que, como el Grupo de Trabajo estaba examinando un enfoque basado en dos modalidades, quedaba por ver si esa disposición podía incluirse en el reglamento y, de ser así, en qué parte de él.

52. Tras un debate, se decidió: i) que se suprimieran los corchetes del párrafo 3 y que el párrafo dijera lo siguiente: “El laudo será definitivo y vinculante para las partes. Las partes deberán cumplir el laudo sin dilación.”; y ii) que, en cuanto a la propuesta de insertar el texto adicional mencionado antes en el párrafo 50, en vista del apoyo a la opinión de que planteaba una cuestión de cierta importancia, se insertara entre corchetes un texto de la índole propuesta, para examinarlo en una futura reunión y determinar, entre otras cosas, la parte del reglamento más indicada para incorporarlo, teniendo presente el enfoque de dos modalidades que podría establecerse.

Párrafo 4

53. Se sugirió que se mantuviera la palabra “laudo”, se suprimiera la palabra “decisión” y se suprimieran los demás corchetes del párrafo.

54. Tras un debate, se convino en modificar el párrafo para que reflejara lo acordado.

55. Algunas delegaciones también opinaron que i) debería permitirse que el tercero neutral rectificara el laudo por iniciativa propia, y ii) debería incluirse una disposición relativa a la interpretación del laudo, paralela a la que figuraba en el artículo 37 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

56. El Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría que incorporara esas disposiciones suplementarias en la siguiente versión del reglamento y que, para no complicar demasiado el párrafo 4, se pusieran entre corchetes en un nuevo artículo 9 *bis*, que se examinaría en una lectura posterior.

57. El Grupo de Trabajo examinó también los plazos establecidos en el párrafo 4, concretamente, si en él se deberían fijar esos plazos y la duración de estos, o si sería preferible que el reglamento contuviera una disposición general por la que el tercero neutral pudiera prorrogar todo plazo de común acuerdo con las partes. A ese respecto, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que en su período de sesiones siguiente le proporcionara una lista de los diversos plazos fijados en el reglamento y sugirió que esta se examinara, conjuntamente con una disposición general relativa a la modificación o prórroga de los plazos con el consentimiento de las partes, en uno de sus futuros períodos de sesiones.

Párrafo 5

58. Algunas delegaciones señalaron que el párrafo 5 se refería supuestamente al derecho aplicable, pero no abordaba adecuada ni exhaustivamente ese tema sustantivo. Se propuso trasladar ese párrafo del proyecto de artículo 9 a la sección del reglamento relativa al derecho aplicable, por ejemplo al previsto documento sobre los principios jurídicos sustantivos para resolver controversias, que figuraría como apéndice del reglamento y al que se alude en el párrafo 2 c) del preámbulo (el

apéndice sobre los “principios jurídicos sustantivos”). Se indicó que ese apéndice podía incorporarse expresamente en el párrafo 5, por ejemplo, por medio de una remisión en ese párrafo, o en otra parte del texto principal del reglamento que indicara que el tercero neutral resolvería las controversias de conformidad con los principios establecidos en ese apéndice.

59. Otra opinión fue que el proyecto de reglamento debía ser compatible, en la medida de lo posible, con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y con la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional -en los que se hacía referencia a la solución de las controversias con arreglo a las condiciones pactadas en el contrato y conforme a los usos del comercio aplicables-, y se consideró que, si bien estos últimos podían o no aplicarse a las controversias que afectaran a consumidores, al dictarse el laudo había que tener en cuenta las condiciones del contrato. Se indicó también que, claramente, el reglamento debía contener los elementos esenciales necesarios para la preparación de un laudo. En apoyo de esa opinión, se propuso mantener la redacción y la ubicación del párrafo 5.

60. Se respondió que i) podía resultar un tanto difícil utilizar selectivamente disposiciones de los textos vigentes de la CNUDMI, ya que estos, por lo general, habían de considerarse en su conjunto, y ii) no cabía hacer referencia a los usos del comercio en el contexto de controversias relativas a operaciones de poco valor que afectaran a consumidores.

61. Habida cuenta de las opiniones divergentes expresadas en el Grupo de Trabajo, se convino en no adoptar una decisión definitiva en relación con el párrafo 5 y volver a examinarlo en una lectura posterior del reglamento.

Párrafo 6

Ubicación

62. Se apoyó la propuesta de trasladar el párrafo 6 del proyecto de artículo 9 del reglamento. Se respaldó la sugerencia de ubicar ese párrafo en el proyecto de artículo 4A, y también la indicación de que podría trasladarse al apéndice sobre principios jurídicos sustantivos mencionado antes en el párrafo 58.

Contenido

63. En cuanto al contenido del párrafo 6, se opinó que toda disposición sobre la carga de la prueba debería ajustarse lo más posible a la enunciada en el artículo 27 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

64. Se propuso también que el comentario reflejara la idea de que la prueba exigida en el reglamento debía ser sencilla, y consistir por ejemplo en la presentación de un recibo para demostrar la compra de determinados bienes. Algunas delegaciones indicaron que presentar una prueba podía resultar problemático, en particular para los consumidores que realizaban sus transacciones en línea. Se dieron ejemplos de la dificultad de demostrar por vía electrónica que un artículo no se había entregado o era defectuoso. Por ello, se señaló que las disposiciones relativas a las pruebas no podían tomarse simplemente de reglamentos de arbitraje que estuvieran concebidos para ocuparse únicamente de casos de operaciones entre empresas, sino que se debía tener en cuenta tanto el carácter informático del procedimiento ODR como el hecho de que muchas veces las partes

que trataban de fundamentar su reclamación eran consumidores relativamente poco versados, y solían actuar sin asesoramiento jurídico.

65. Se apoyó en cierta medida la propuesta de fijar requisitos en materia de prueba concebidos expresamente para cada categoría o tipo de reclamación, centrándose, en cada caso, en la forma en que la parte interesada podría, en la práctica, presentar las pruebas necesarias.

66. Se propuso incorporar en el reglamento una disposición por la que se invirtiera la carga de la prueba en las situaciones en que la parte a la que se exigía demostrar un hecho no estuviese en posesión de las pruebas necesarias o no pudiese obtenerlas fácilmente. Se señaló que ello debía considerarse una excepción, que podría invocarse cuando las circunstancias del caso lo requirieran. Esa propuesta recibió algún apoyo, y se sugirió que se abordara en el comentario del reglamento o en un documento en que se fijaran directrices y requisitos mínimos aplicables a los terceros neutrales (“directrices para los terceros neutrales”; véase el preámbulo, párrafo 2 b), enunciado en el párrafo 7 del documento A/CN.9/WG.III/WP.117).

Conclusión

67. Tras un debate, se llegó a la conclusión de que el párrafo abordaba una cuestión importante pero que su ubicación en el proyecto de artículo 9 era inapropiada, por lo que, conservando el texto entre corchetes, debía trasladarse provisionalmente al proyecto de artículo 4A. Se convino además en que también debía incluirse, con miras a su examen ulterior y poniéndola igualmente entre corchetes, la propuesta formulada en el párrafo 66 relativa a la inversión de la carga de la prueba.

7. Otras disposiciones

Proyecto de artículo 10 (Idioma de las actuaciones)

68. El Grupo de Trabajo examinó el proyecto de artículo 10, que figuraba en el párrafo 53 del documento A/CN.9/WG.III/WP.117/Add.1.

69. Varias delegaciones se mostraron partidarias de que el reglamento contuviera una disposición sobre el idioma de las actuaciones, entre otras razones porque el mero hecho de que un consumidor realizara una operación en un idioma no significaba que pudiera ser parte en un procedimiento ODR en ese idioma, por lo que el reglamento debía establecer medidas de protección a ese respecto.

70. Se sostuvo, por una parte, que una buena base para determinar el idioma de las actuaciones eran las disposiciones del Reglamento de Arbitraje y la Ley Modelo de la CNUDMI, conforme a las cuales la decisión a ese respecto competía al tercero neutral previo acuerdo de las partes. Otras delegaciones argumentaron, en cambio, que dichas normas no eran aplicables a las controversias en línea en que fueran partes consumidores, porque el arbitraje comercial regulado por esos instrumentos de la CNUDMI tenía una serie de aspectos que lo diferenciaban de ellas, como el hecho de que los árbitros fueran elegidos por las partes, el de que la cláusula compromisoria se negociara individualmente y el de que las partes pudieran tener acceso a recursos como la traducción.

71. A fin de asegurar que se tuvieran en cuenta los problemas relacionados con el idioma que pudiesen afectar a los consumidores en operaciones transfronterizas,

otras delegaciones apoyaron en diverso grado las siguientes sugerencias: i) que se incluyera en el artículo 10 o en las directrices para los terceros neutrales el texto que figuraba en el párrafo 59 del documento A/CN.9/WG.III/WP.117/Add.1, en relación con lo cual una delegación sugirió que la formulación fuese menos imperativa (por ejemplo, “podrá establecer” en lugar de “establecerá”); ii) que en el comentario o las directrices se señalara que sería preferible que cada parte utilizara su propio idioma; y iii) que un acuerdo sobre el idioma concertado entre las partes antes de la controversia tal vez sea menos convincente que un acuerdo concertado después de la controversia, ya que los consumidores posiblemente no prestarán mucha atención antes de una controversia a una opción sobre el idioma en una cláusula compromisoria de un acuerdo en línea.

“Salvo que el tercero neutral decida otra cosa”

72. Varias delegaciones fueron partidarias de otorgar facultades residuales al tercero neutral para determinar el idioma de las actuaciones cuando no lo hubieran determinado las partes.

73. Otras delegaciones señalaron que tal vez sería problemático que el tercero neutral pudiera anular un acuerdo entre las partes, tanto por el principio de la inmutabilidad de los contratos como porque cabía la posibilidad de que el tercero neutral no hablara el mismo idioma que las partes.

74. Se sostuvo que la facultad general prevista en el proyecto de artículo 7 1) *bis*, ejerciendo la cual el tercero neutral dirigiría el procedimiento evitando demoras o gastos innecesarios y cumpliendo un proceso justo y eficiente para resolver el litigio, en particular si se interpretaba teniendo a la vista el futuro documento que habría de redactarse sobre las directrices y los requisitos mínimos para los terceros neutrales.

Propuesta de un nuevo proyecto de artículo 10

75. Se propuso reemplazar el proyecto de artículo 10 por el texto siguiente:

“Artículo 10

Párrafo 1

El procedimiento ODR será sustanciado en el idioma o los idiomas convenidos por las partes en el momento de la apertura de ese procedimiento.

Párrafo 2

Si las partes no se ponen de acuerdo respecto del idioma o los idiomas del procedimiento, el tercero neutral deberá determinar el idioma o los idiomas que se utilizarán, teniendo en cuenta los derechos que asisten a las partes en el procedimiento en virtud del artículo [x].

Párrafo 3

El idioma o los idiomas que se determinen conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 serán los que se utilicen en todas las comunicaciones durante el procedimiento ODR.

Párrafo 4

Todo proveedor de servicios ODR que tenga trato con partes que usen distintos idiomas se cerciorará de que sus sistemas, su reglamento y los terceros neutrales tengan en cuenta esas diferencias y establecerá mecanismos para atender a las necesidades de las partes a ese respecto.”

76. Esa propuesta recibió amplio apoyo. Se sugirió modificarla a fin de aludir, en el párrafo 2 de la propuesta, no a un artículo todavía por determinar, sino más bien a los poderes otorgados al tercero neutral, ya enunciados en el artículo 7 1) *bis*, a fin de que cumpla un proceso justo y eficiente para resolver el litigio. En relación con el párrafo 2, se señaló también que podría agregarse una disposición por la que se protegiera a los consumidores en el caso de que estos no comprendiesen realmente el idioma que hubiesen acordado utilizar.

77. Con respecto al párrafo 4 de la propuesta, se señaló también que el requisito previsto en él parecía imponer a los proveedores de servicios ODR responsabilidades que parecía más apropiado señalar en el documento relativo a las directrices que se prepararía como anexo o apéndice del reglamento.

78. Además, se señaló que con respecto al tercer párrafo de la propuesta, se debería agregar texto en que se previera que las pruebas podían presentarse en el idioma original, acompañadas de una traducción.

79. Atendiendo a esa sugerencia, se propuso agregar al texto propuesto en el párrafo 75 los dos párrafos siguientes:

“Párrafo 5

Todo documento adjunto a las comunicaciones y todo documento complementario o probatorio podrá presentarse en el curso del procedimiento de ODR en su idioma original, siempre que no se haya impugnado su contenido.

Párrafo 6

Si una reclamación se basa en un documento cuyo contenido se haya impugnado, el tercero neutral podrá exigir a la parte interesada que presente ese documento acompañado de una traducción a un idioma que la otra parte comprenda.”

80. Se expresó apoyo al nuevo párrafo 5 de la propuesta. En cuanto al nuevo párrafo 6 propuesto, varias delegaciones expresaron inquietud en el sentido de que la disposición en él contenida podría suponer un costo y una carga desproporcionados para los consumidores. Se convino en seguir examinando el párrafo 6 durante una lectura posterior del reglamento.

81. Hubo consenso respecto de que el texto actual del proyecto de artículo 10, que figura en el párrafo 53 del documento A/CN.9/WG.III/WP.117/Add.1, se debería reemplazar por los párrafos 1 a 6 propuestos en los párrafos 71 y 75 del presente documento, con las modificaciones secundarias que la secretaría estimase apropiado introducir entre corchetes para su examen posterior.

V. Labor futura

82. El Grupo de Trabajo observó que la celebración de su 27º período de sesiones estaba prevista para los días 20 a 24 de mayo de 2013 en Nueva York.

Anexo

Nota de la Secretaría

Durante el 26° período de sesiones del Grupo de Trabajo III (Solución de Controversias en Línea), varias delegaciones presentaron a la Secretaría el texto que figura a continuación, que se había examinado en el marco de consultas oficiosas celebradas paralelamente al período de sesiones.

El texto se reproduce en la forma en lo recibió la Secretaría.

Sinopsis de normas que ofrecen opiniones múltiples en la solución de controversias en línea (ODR)

Tras consultas oficiosas en que quedaron de manifiesto las posturas divergentes de diversas delegaciones sobre los procedimientos que se deberían aplicar a la ODR, la delegación de la República Checa desea presentar el texto siguiente como base de futuras deliberaciones.

Reconociendo que el efecto de los acuerdos de arbitraje anteriores a una controversia resulta problemático al formularse los aspectos del reglamento de ODR relativos a los compradores, se presentan a continuación dos opiniones sobre la forma de reflejar esa cuestión.

Opinión 1

Se señaló que sería necesario agregar, en la parte indicada del texto del reglamento genérico, una disposición para fijar un procedimiento en que se diese cabida a los acuerdos de arbitraje vinculantes anteriores a la controversia, garantizando al mismo tiempo que el proceso de ODR no pasara a la etapa de arbitraje sin el consentimiento del comprador, si este residía en un país conforme a cuya legislación vigente los acuerdos pertinentes no fueran vinculantes para el comprador.

Opinión 2

Se señaló que sería necesario establecer, en la parte indicada del texto del reglamento genérico, un procedimiento en que se diese cabida a los acuerdos de arbitraje de carácter vinculante previos a la controversia, pero sin imponer los laudos derivados de tales acuerdos a un comprador que no pudiera concertarlos por impedirlo el derecho aplicable del que las partes no podían apartarse.

Procedimiento ODR

Proyecto de artículo A (Negociación y arreglo)

1. Tras la recepción de la contestación y, si procede, de la contrademanda a que se hace referencia en el artículo [XX, párrafo[s] ()-()], en la plataforma ODR y de la notificación de esta al demandante, las partes tratarán de resolver su controversia mediante negociaciones directas, incluso, en su caso, mediante los métodos de comunicación que ofrezca la plataforma ODR.

2. Si el demandado no da al proveedor de servicios ODR su contestación en un plazo de siete (7) días naturales a partir de [...], se presumirá que ha rechazado la invitación a negociar y el procedimiento ODR pasará automáticamente a la modalidad de solución por un tercero neutral seleccionada en el acuerdo de ODR, y en ese momento el proveedor de servicios ODR deberá proceder, sin dilación, al nombramiento de un tercero neutral con arreglo a lo previsto en el artículo XX (Nombramiento de un tercero neutral).
3. Si las partes no han resuelto su controversia mediante negociación en el plazo de diez (10) días naturales a partir de [...], el procedimiento ODR pasará automáticamente a la(s) etapa(s) de solución por un tercero neutral seleccionada(s) en el acuerdo ODR.
4. Disposición sobre prórroga.
5. Si se llega a un arreglo durante la etapa de negociación, las condiciones de ese arreglo se consignarán en la plataforma ODR, y en ese momento se dará automáticamente por concluido el procedimiento ODR.

Proyecto de artículo B (Solución por un tercero neutral)

1. El proceso o procesos de solución de controversias utilizado para la solución por un tercero neutral se determinará mediante una cláusula de ODR acordada por el demandante y el demandado y podrá consistir en: a) el arreglo facilitado; b) el arbitraje; c) el arreglo facilitado que, de ser infructuoso, irá seguido del arbitraje; o d) el arreglo facilitado que, de ser infructuoso, irá seguido por una resolución o recomendación.
2. Arreglo facilitado: cuando la cláusula ODR especifique el arreglo facilitado, el tercero neutral evaluará la controversia basándose en la información presentada y se comunicará con las partes para tratar de llegar a un acuerdo.
 - a) Cuando la cláusula ODR especifique el arbitraje o la resolución/recomendación, el tercero neutral podrá ofrecer a las partes la oportunidad de convenir en iniciar un arreglo facilitado antes de esa etapa del procedimiento ODR.
3. Si las partes llegan a un arreglo, este se consignará en la plataforma ODR, y en ese momento, a reserva de lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 5, se dará automáticamente por concluido el procedimiento ODR.
4. Si las partes no llegan a un arreglo dentro de diez (10) días naturales, y la cláusula ODR prevé el arbitraje o la resolución/recomendación, las partes procederán a la etapa de arbitraje o resolución/recomendación del procedimiento ODR. Cuando la cláusula ODR no prevea el arbitraje o la resolución/recomendación, se dará automáticamente por terminado el procedimiento ODR, a menos que ambas partes acuerden, en un escrito presentado a la plataforma ODR, que desean proceder al arbitraje o a la resolución/recomendación.
 - a) En el caso del arbitraje, el tercero neutral emitirá un laudo con arreglo a lo dispuesto en [el artículo 9].
 - b) En el caso de la resolución/recomendación, el tercero neutral emitirá una decisión de conformidad con las condiciones de la cláusula ODR.
5. [Incapacidad del tercero neutral para mantener la imparcialidad o la independencia.]

B. Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 26º período de sesiones

(A/CN.9/WG.III/WP.117 y Add.1)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-4
II. Solución de controversias en línea (ODR) en operaciones electrónicas transfronterizas: proyecto de reglamento	5-59
A. Observaciones generales	5-6
B. Notas sobre el proyecto de reglamento	7-59
1. Artículos introductorios	7-35
2. Apertura del procedimiento	36-59

I. Introducción

1. En su 43º período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010), la Comisión convino en que se estableciera un Grupo de Trabajo que se ocupara de la solución en línea de controversias surgidas a raíz de operaciones transfronterizas de comercio electrónico, incluidas las operaciones entre empresas y entre empresas y consumidores. Se convino también en que la forma de la norma jurídica se decidiría una vez que se hubiera examinado con más detalle el nuevo tema¹. En su 44º período de sesiones (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011), la Comisión reafirmó el mandato del Grupo de Trabajo sobre la solución de controversias en línea surgidas a raíz de operaciones transfronterizas de comercio electrónico, incluidas las operaciones entre empresas y entre empresas y consumidores. La Comisión decidió que, si bien el Grupo de Trabajo debía tener libertad para interpretar que su mandato abarcaba las operaciones entre consumidores y para elaborar un posible reglamento que las regulara cuando fuera preciso, debería tener especialmente en cuenta la necesidad de no dejar de lado la legislación de protección del consumidor. La Comisión decidió también que, en general, al cumplir su mandato, el Grupo de Trabajo debería asimismo tener muy presentes las consecuencias que sus deliberaciones pudieran tener en la protección del consumidor e informar al respecto a la Comisión en su siguiente período de sesiones².

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), párr. 257.*

² *Ibid., sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 218.*

2. En su 22º período de sesiones (Viena, 13 a 17 de diciembre de 2010)³, el Grupo de Trabajo inició su examen del tema de la solución de controversias en línea y pidió a la Secretaría que, a reserva de los fondos de que dispusiera, preparara un proyecto de reglamento genérico para la solución de controversias en línea (ODR) en el que se tuviera en cuenta que los tipos de demandas aptas para la ODR serían las relacionadas con operaciones transfronterizas de bajo valor y muy numerosas realizadas entre empresas y entre empresas y consumidores (A/CN.9/716, párr. 115). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió también a la Secretaría que enunciara la información de que dispusiera sobre el método ODR, mencionando sitios de Internet u otras fuentes en que puedan encontrarse (A/CN.9/716, párr. 115). El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que esa lista puede consultarse en el sitio de la CNUDMI en Internet⁴.

3. En sus períodos de sesiones 23º (Nueva York, 23 a 27 de mayo de 2011)⁵, 24º (Viena, 14 a 18 de noviembre de 2011)⁶ y 25º (Nueva York, 21 a 25 de mayo de 2012)⁷, el Grupo de Trabajo examinó el proyecto de reglamento genérico que figuraba en los documentos A/CN.9/WG.III/WP.107, A/CN.9/WG.III/WP.109, y A/CN.9/WG.III/WP.112 y Add.1, respectivamente. En su 24º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que, en función de los recursos disponibles, preparara una versión revisada del proyecto de reglamento genérico, así como documentación en la que se trataran las cuestiones de las directrices para los terceros neutrales, las reglas mínimas para los proveedores de servicios ODR, los principios jurídicos sustantivos para la solución de controversias y un mecanismo para la ejecución transfronteriza (A/CN.9/721, párr. 140, y A/CN.9/739, párr. 151). En su 25º período de sesiones, el Grupo de Trabajo procedió a deliberar sobre el proyecto de reglamento (A/CN.9/744).

4. La presente nota contiene un proyecto anotado de reglamento genérico para la solución en línea de controversias surgidas a raíz de operaciones transfronterizas de comercio electrónico (“el Reglamento”), teniendo en cuenta las deliberaciones mantenidas por el Grupo de Trabajo en sus períodos de sesiones 22º, 23º, 24º y 25º.

II. Solución de controversias en línea (ODR) en operaciones electrónicas transfronterizas: proyecto de reglamento

A. Observaciones generales

5. El presente Reglamento se ha elaborado de acuerdo con la decisión del Grupo de Trabajo de preparar un proyecto de reglamento genérico para la vía ODR, teniendo en cuenta que los tipos de controversias en que se acudiría a esa vía serían

³ El informe sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo en su 22º período de sesiones figura en el documento A/CN.9/716.

⁴ www.uncitral.org/uncitral/en/publications/online_resources_ODR.html.

⁵ El informe sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo en su 23º período de sesiones figura en el documento A/CN.9/721.

⁶ El informe sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo en su 24º período de sesiones figura en el documento A/CN.9/739.

⁷ El informe sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo en su 25º período de sesiones figura en el documento A/CN.9/744.

operaciones electrónicas transfronterizas en gran volumen y de poca cuantía entre empresas y entre empresas y consumidores. El Reglamento preparado de esa forma, y cuya aplicación, según su proyecto de artículo 1, requiere el acuerdo de las partes, es de naturaleza contractual y está sujeto a legislación vinculante.

6. Al estudiar el Reglamento se plantean varias cuestiones relacionadas con la concepción de un marco general de la vía ODR. En los documentos A/CN.9/WG.III/WP.113, A/CN.9/WG.III/WP.114 y A/CN.9/WG.III/WP.115 se abordan algunas de esas cuestiones, como las directrices y los requisitos mínimos para los proveedores de servicios ODR y los terceros neutrales, así como los principios jurídicos sustantivos propuestos para decidir reclamaciones y medidas cautelares por la vía ODR.

B. Notas sobre el proyecto de reglamento

1. Artículos introductorios

7. Proyecto de preámbulo

“1. El reglamento de la CNUDMI para la solución de controversias en línea (“el Reglamento”) tiene la finalidad de ser utilizado en el contexto de operaciones transfronterizas de poco valor y de gran volumen realizadas por medios electrónicos de comunicación.

2. Se ha previsto que el presente Reglamento sea aplicado en un marco jurídico para la solución de controversias en línea, que conste de los siguientes documentos que [se adjuntan al presente Reglamento como apéndices y que] formarán parte del mismo:

[a) Directrices y requisitos mínimos para los proveedores de servicios de solución de controversias en línea;]

[b) Directrices y requisitos mínimos para los terceros neutrales;]

[c) Principios jurídicos sustantivos para resolver controversias;]

[d) Mecanismo transfronterizo de ejecución;]

[...]

[3. [Toda regla separada y suplementaria] [Todo documento separado y suplementario] deberá ser conforme al Reglamento.]”

Observaciones

Párrafo 1)

8. El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que, en uno de sus anteriores periodos de sesiones, se formuló la propuesta de que en el proyecto de preámbulo se indicara que el Reglamento tenía por objeto ser aplicable también a las controversias relativas a la “compraventa de mercancías y a la prestación de servicios” (A/CN.9/739, párr. 19).

Párrafo 2)

9. En su 24º período de sesiones, el Grupo de Trabajo observó que la lista de documentos enunciada en el párrafo 2) no era exhaustiva (A/CN.9/739, párr. 21). El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar cuáles de esos documentos y qué documentos adicionales debería preparar en cumplimiento de su mandato. El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que en los documentos A/CN.9/WG.III/WP.113, A/CN.9/WG.III/WP.114 y A/CN.9/WG.III/WP.115 se abordan cuestiones relacionadas con los documentos mencionados en el párrafo 2) (véase el párrafo 6 *supra*).

Párrafo 3)

10. Los proveedores de servicios ODR pueden decidir adoptar reglas suplementarias para abordar cuestiones que no estén contempladas en el Reglamento y que puedan requerir un tratamiento distinto por parte de cada uno de ellos, como, por ejemplo, los costos, la definición de los días de calendario o las respuestas a la impugnación de los terceros neutrales.

11. **Proyecto de artículo 1 (Ámbito de aplicación)**

“1. El Reglamento será aplicable cuando las partes en una operación realizada mediante comunicaciones electrónicas[, [en el momento de la operación] [ya sea en el momento de la operación o después de que surja una controversia],] hayan convenido explícitamente que las controversias dimanantes de esa operación y que entren en el ámbito del Reglamento ODR se resolverán recurriendo a la vía ODR en virtud del Reglamento.

[1 bis. El acuerdo explícito mencionado en el párrafo 1) supra requiere un acuerdo independiente de esa operación y que se notifique sin ambigüedades al comprador que toda controversia que surja de la operación y que entre en el ámbito del Reglamento ODR se resolverá exclusivamente mediante un procedimiento ODR de conformidad con el presente Reglamento.]

[2.

Opción 1: [El presente Reglamento no será aplicable cuando la ley del Estado de residencia del comprador disponga que los acuerdos de someter una controversia al Reglamento ODR solamente serán vinculantes para el comprador cuando se hayan concertado después de surgir la controversia y cuando el comprador no haya dado ese consentimiento después de surgir la controversia o no haya confirmado ese acuerdo que expresó en el momento de la operación.]

Opción 2: [El presente Reglamento regirá los procedimientos ODR, con la salvedad de que cuando alguno de los artículos del Reglamento esté en conflicto con una disposición de la ley aplicable a los procedimientos ODR que las partes no puedan excluir, tal disposición prevalecerá.]

Opción 3: [Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento prevalecerá sobre una regla de derecho cuyo objetivo sea la protección del consumidor.]]

3. A fin de poder aplicar el Reglamento, cada parte deberá, [en el momento de dar su acuerdo explícito a que se sometan a ODR en virtud del Reglamento las controversias dimanantes de la operación, también] proporcionar su información de contacto por vía electrónica.”

*Observaciones**Párrafos 1) y 1) bis*

12. La propuesta actual de enunciado para los párrafos 1) y 1) *bis* prevé como requisito que haya acuerdo para someter las controversias a la vía ODR y que ese acuerdo sea independiente de la operación. Se sugirió que si hubiera un acuerdo separado se garantizaría mejor que el consumidor diera su “consentimiento con conocimiento de causa” al convenir en someter las controversias a la vía ODR (A/CN.9/744, párrs. 23 y 24). El consentimiento de las partes podría expresarse en forma de una casilla separada (acuerdo *click-wrap*) accesible desde la operación pertinente o vinculado a ella.

13. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si en el párrafo 1) habría que especificar claramente que el acuerdo de someter controversias a la vía ODR en virtud del Reglamento deberá concertarse al mismo tiempo que la operación sustantiva, aun cuando algunos consumidores requieran un “clic” de confirmación en una fase ulterior en que el derecho imperativo exige el acuerdo del consumidor después de surgir la controversia para pasar a la fase de arbitraje de la solución de una controversia.

14. Concretamente, se sugirió en el 25º período de sesiones del Grupo de Trabajo que un “segundo clic” de un consumidor en una fase posterior a la controversia para confirmar su consentimiento de que se someta su controversia a un procedimiento ODR conforme al Reglamento tal vez atenuaría las reservas expresadas en el sentido de que en algunos Estados los consumidores no podían concertar acuerdos de arbitraje antes de que surgiera una controversia (A/CN.9/744, párr. 33). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar:

i) en qué etapa del procedimiento ODR sería apropiado realizar este segundo “clic” de confirmación y, en particular, si una nueva confirmación en la etapa de arbitraje (es decir, tras el fracaso de las etapas de negociación y de solución negociada) haría que todos los consumidores se beneficiaran de las dos primeras etapas del procedimiento ODR por el hecho de haber aceptado el Reglamento ODR en el momento de concertar la operación;

ii) si todos los consumidores o solamente los consumidores de ciertos Estados estarían obligados a hacer ese “clic” de confirmación tras surgir las controversias, teniendo presentes las dificultades que entrañan la definición o la determinación de la “residencia habitual” de un consumidor. Esta cuestión puede ser abordada por los proveedores regionales de servicios ODR, si disponen de la capacidad de conocer y averiguar los requisitos de la legislación de protección del consumidor en sus respectivas regiones;

o bien,

iii) si un determinado acto, como la presentación de una demanda, podría equipararse al cumplimiento del requisito de confirmación por parte del consumidor, después de surgir la controversia, de su consentimiento para someterla a un procedimiento ODR (véase A/CN.9/744, párr. 20).

Párrafo 2)

15. Si bien inicialmente las opciones 1 y 2 no se propusieron como variantes, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si dejando solamente una de las opciones quedaría suficientemente claro en el Reglamento que los procedimientos ODR están sujetos a la legislación nacional de protección del consumidor, en particular en los Estados en que los consentimientos previos a la controversia para recurrir al arbitraje con consumidores no sean vinculantes para los consumidores. Se ha incluido en el texto, entre corchetes, una tercera opción que tal vez el Grupo de Trabajo desee examinar como variante adicional, que se basa en una nota relativa al artículo 1 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico.

Párrafo 3)

16. En su 25º período de sesiones, el Grupo de Trabajo convino en mantener el párrafo 3) (anteriormente párrafo 2)), en el que se fija como requisito para recurrir al Reglamento la obligación de que las partes faciliten su información de contacto (A/CN.9/744, párr. 39). En aras de la claridad se han agregado las palabras “por vía electrónica”.

17. Dado que este párrafo se expresa como requisito para la aplicabilidad del Reglamento, el Grupo de Trabajo tal vez desee plantearse la determinación de un plazo para el cumplimiento de ese requisito. Se han agregado al texto palabras entre corchetes para reflejar las opciones temporales que actualmente se fijan en el proyecto de artículo 3, y el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la conveniencia de trasladar este proyecto de párrafo al proyecto de artículo 3 (véase A/CN.9/744, párrs. 42 y 68 a 71).

18. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar sus deliberaciones acerca de la necesidad de que las partes proporcionen una dirección electrónica actualizada y en funcionamiento, y el hecho de que el Reglamento, tal como está actualmente redactado, no prevé ninguna sanción para el caso en que una de las partes, deliberadamente o por negligencia, no lo haga (véase A/CN.9/744, párr. 43).

19. Proyecto de artículo 2 (Definiciones)

“A los efectos del presente Reglamento:

ODR

1. Por ‘ODR’ se entenderá la solución en línea de controversias, que constituye un mecanismo para resolver controversias facilitado mediante el empleo de las comunicaciones electrónicas y demás tecnologías de la información y de las comunicaciones.

2. Por ‘plataforma ODR’ se entenderá una o más de una plataforma para la solución informática de controversias consistente en un sistema para la generación, el envío, la recepción, el archivo, el intercambio o toda otra técnica de procesamiento de comunicaciones electrónicas que sea utilizable por la vía ODR.

3. Por ‘proveedor de servicios ODR’ se entenderá un proveedor de servicios de solución de controversias en línea consistente en una entidad que administra procedimientos ODR de modo que las partes puedan resolver sus controversias de conformidad con el Reglamento, independientemente de si ese proveedor dispone o no de una plataforma ODR.

Partes

4. Por 'demandante' se entenderá toda parte en una controversia que inicie un procedimiento por vía ODR emitiendo un aviso conforme al presente Reglamento.

5. Por 'demandado' se entenderá el destinatario del aviso de apertura emitido.

6. Por 'tercero neutral' se entenderá toda persona que preste asistencia a las partes en orden a la solución de la controversia y/o que [emita un laudo u otra decisión respecto de la controversia] [resuelva la controversia] de conformidad con el Reglamento.

Comunicación

7. Por 'comunicación' se entenderá toda declaración, exposición, aviso, contestación, presentación, notificación o solicitud que una parte a la que sea aplicable el Reglamento haya de efectuar en el curso de un procedimiento tramitado por ODR.

8. Por 'comunicación electrónica' se entenderá toda comunicación que una persona a la que sea aplicable el Reglamento curse por medios de información generados, expedidos, recibidos o archivados por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, entre los que cabe citar, a título no exhaustivo, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telefax, los servicios de mensajes cortos (SMS), las conferencias, charlas y foros por Internet o los microblogs, e incluirá toda información en forma analógica, como los objetos, documentos, imágenes, textos y sonidos a los que se les da formato digital a fin de poder ser procesados por un ordenador u otros aparatos electrónicos.

[9. Por 'escrito' se entenderá un mensaje de datos que contenga información que sea accesible para su ulterior consulta.]”

*Observaciones**Observaciones generales*

20. El Grupo de Trabajo tal vez desee revisar el orden en que figuran las definiciones, que se han reorganizado por temas (en vez de dejarlas en estricto orden alfabético), a fin de establecer un orden coherente entre las versiones en distintos idiomas del Reglamento, conforme a lo solicitado por el Grupo de Trabajo en su 25º período de sesiones (A/CN.9/744, párr. 47).

Párrafo 6): “tercero neutral”

21. La primera opción entre corchetes que figura en el párrafo 6) y la definición de “tercero neutral” (anteriormente párrafo 4)) se han modificado ligeramente a fin de reflejar el texto del párrafo 1 del artículo 33 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, de conformidad con lo que se sugirió durante el 25º período de sesiones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/744, párr. 53). En la segunda opción entre corchetes se ha omitido toda referencia a los términos “laudo” o “decisión”. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar sus deliberaciones (A/CN.9/744, párr. 54)

en el sentido de que la finalidad de esta disposición no es determinar lo que pueda o no hacer el tercero neutral sino definir su función.

Párrafo 9): “escrito”

22. En el 25º período de sesiones del Grupo de Trabajo se propuso que se agregara a la lista de definiciones una definición del término “escrito” que reflejara el texto del artículo 6 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (A/CN.9/744, párr. 59).

23. Actualmente, el término “escrito” aparece dos veces en el proyecto de reglamento (en los párrafos 2) y 4) del proyecto de artículo 9) como requisito para la decisión o el laudo emitido por el tercero neutral. El Grupo de Trabajo tal vez desee también examinar si, a raíz de la inserción de esa definición, habría que incluir el término “escrito” en relación con el acuerdo en el párrafo 1) *bis* del artículo 1 del Reglamento.

24. Proyecto de artículo 3 (Comunicaciones)

“1. Todas las comunicaciones intercambiadas en el curso de las actuaciones por ODR serán transmitidas por medios electrónicos por conducto de la plataforma ODR designada por el proveedor de servicios ODR.

2. [La dirección electrónica designada] [Las direcciones electrónicas designadas] del demandante, a efectos de todas las comunicaciones que se produzcan en virtud del Reglamento [será] [serán]:

Opción 1: [[la] [las] [indicada] [indicadas] en el aviso del procedimiento ODR (“el aviso”), a menos que el demandante notifique otra cosa al proveedor de servicios ODR].

Opción 2: [[la] [las] [notificada] [notificadas] por el demandante al proveedor de servicios ODR al aceptar el Reglamento [conforme al párrafo 3) del artículo 1 supra] y que se [haya] [hayan] actualizado y comunicado al proveedor de servicios ODR en cualquier momento posterior durante el procedimiento ODR (inclusive al especificarse en el aviso una dirección electrónica actualizada, si procede)].

3. [La dirección electrónica] [Las direcciones electrónicas] a efectos de comunicación del aviso por el proveedor de servicios ODR al demandado [será] [serán]:

Opción 1: [[la] [las] que haya notificado el demandado al proveedor de servicios ODR al aceptar el Reglamento [conforme al párrafo 3) del artículo 1 supra] y que se [haya] [hayan] actualizado y comunicado al demandante o al proveedor de servicios ODR en cualquier momento anterior a la emisión del aviso. Posteriormente, el demandado podrá actualizar su dirección electrónica notificándola al proveedor de servicios ODR en cualquier momento durante el procedimiento ODR.]

Opción 2: [[La dirección] [Las direcciones] del demandado que el demandante haya proporcionado. Posteriormente, [la dirección electrónica designada] [las direcciones electrónicas designadas] del demandado a los efectos de todas las comunicaciones que surjan en virtud del Reglamento [será] [serán] [la] [las] que el demandado haya notificado al proveedor de

servicios ODR al aceptar el Reglamento [o cualquier modificación notificada durante el procedimiento ODR y actualizada y comunicada al proveedor de servicios ODR en cualquier momento posterior durante el procedimiento ODR]].

[4.

Opción 1: La comunicación electrónica se tendrá por recibida, conforme al Reglamento, cuando pueda ser recuperada por el destinatario de la comunicación [en la plataforma ODR] [[siempre y cuando se haya notificado al destinatario al respecto] [de conformidad con el párrafo 6) supra]]. [Se presumirá que una comunicación electrónica puede ser recuperada cuando el destinatario haya recibido una notificación al respecto de conformidad con el párrafo 6) infra]. [El tercero neutral podrá, a su discreción, prorrogar cualquier plazo cuando el destinatario de una comunicación demuestre que existe una buena razón por la que no puede recuperar esa comunicación desde la plataforma.]

Opción 2: Una comunicación se tendrá por recibida cuando, tras su presentación en la plataforma ODR de conformidad con el párrafo 1), el proveedor de servicios ODR notifique a las partes que dispone de esa comunicación de conformidad con el párrafo 6). [El tercero neutral podrá, a su discreción, prorrogar cualquier plazo en caso de que el destinatario de una comunicación demuestre que existe una buena razón por la que no puede recuperar esa comunicación desde la plataforma.]

5. *El proveedor de servicios ODR hará llegar [rápidamente] [sin demora] los acuses de recibo de comunicaciones electrónicas entre las partes y el tercero neutral a todas las partes [y al tercero neutral] enviándolas a sus respectivas direcciones electrónicas designadas.*

6. *El proveedor de servicios ODR notificará [rápidamente] [sin demora] a todas las partes y al tercero neutral toda comunicación electrónica recibida en la plataforma ODR."*

Observaciones

Párrafo 1)

25. En su 25º período de sesiones, el Grupo de Trabajo convino en que el párrafo 1) reflejara el principio de que todas las comunicaciones realizadas durante el proceso ODR se tramitan por la plataforma ODR (A/CN.9/744, párrs. 62 y 63). Por consiguiente, en todo el Reglamento se han insertado palabras entre corchetes para aclarar que, mientras que las partes *comunican [por ejemplo, un aviso] al proveedor de servicios ODR*, el proceso requiere que se *transmita una comunicación a la plataforma ODR* (véase, a título de ejemplo, el párrafo 1) del proyecto de artículo 4A *infra*).

Párrafos 2) y 3)

26. En su 25º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara un texto en el que se reflejaran las distintas opciones y formas en que cabría redactar los párrafos 2) y 3) del proyecto de artículo 3 con miras a que fueran examinadas (A/CN.9/744, párr. 71). A este respecto se estimaron pertinentes

varias consideraciones: i) el deseo de evitar toda posible confusión respecto del término “aviso” antes de que ese término se definiera formalmente en el Reglamento; ii) el apoyo a la propuesta de que la dirección de contacto designada para las partes fuera la dirección de contacto facilitada en el momento en que las partes aceptaran el reglamento; y iii) la posible dificultad que podría tener que afrontar un demandante cuando la dirección electrónica del demandado cambiara durante el período que mediara entre el acuerdo de someter una posible controversia a un procedimiento ODR regido por el Reglamento y el momento en que surgiera una controversia en la práctica, y cuando esa modificación no se hubiera comunicado al proveedor de servicios ODR.

27. Además de esas consideraciones y de la solicitud del Grupo de Trabajo, la Secretaría ha insertado palabras entre corchetes en el párrafo 2), como opción 2, y en el párrafo 3), como opción 1. Esas opciones tienen la finalidad de regular los casos en que: a) un aviso se transmita en el primer caso a una o varias direcciones electrónicas proporcionadas por el demandado en el momento de aceptar el Reglamento (dando por sentado que la aceptación del Reglamento se produce en el momento de concertar la operación y que, por lo tanto, la aceptación es anterior al aviso; y b) la dirección o las direcciones electrónicas facilitadas se mantienen constantes y actualizadas durante todo el procedimiento.

28. El Grupo de Trabajo puede recordar que, como requisito para utilizar el Reglamento (proyecto de párrafo 3) del proyecto de artículo 1) se requiere a ambas partes que comuniquen sus respectivas direcciones electrónicas; la opción prevista en el párrafo 3) de permitir al demandante comunicar una dirección electrónica al demandado en el aviso (opción 2) puede ir en contra de esa disposición cuando el acuerdo de recurrir al reglamento haya tenido lugar en el momento de concertarse la operación.

29. A este respecto, tanto el párrafo 2) como el párrafo 3) guardan una estrecha relación con los párrafos 1) y 1) *bis* del proyecto de artículo 1 en lo que respecta al momento y a la naturaleza de la aceptación del Reglamento, y también con el párrafo 3) del proyecto de artículo 1, que especifica que, para poder recurrir al Reglamento, cada parte deberá proporcionar su información de contacto.

Párrafo 4)

Opción 1

30. En su último período de sesiones el Grupo de Trabajo observó que el párrafo 4), que en su enunciado inicial reflejaba el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (“la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas”), debería redactarse de nuevo teniendo presente la estrecha relación de ese párrafo con el párrafo 6), y teniendo en cuenta además el párrafo 5 del artículo 2 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (A/CN.9/744, párr. 73).

31. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar que en la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas se establece explícitamente la presunción de que toda comunicación electrónica es recuperable en cuanto llega a la dirección electrónica del destinatario (artículo 10, párrafo 2 de la Convención; véase también A/CN.9/WG.III/WP.112, párr. 26). Dado que esa presunción no puede trasladarse directamente a un contexto ODR, donde las comunicaciones se presentan a la

plataforma ODR y no directamente a una dirección electrónica, conforme al párrafo 1) del proyecto de artículo 3, tal vez habría que explicar o introducir alguna reserva en lo que respecta a la capacidad de recuperación de comunicaciones; a este respecto se han insertado en el texto dos opciones entre corchetes para que las examine el Grupo de Trabajo, que se basan en la relación de este párrafo con el párrafo 6).

32. No obstante, el Grupo de Trabajo tal vez desee tomar en consideración que el párrafo 4) tiene la finalidad de regir el momento de la recepción; a este respecto, el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si el momento de recepción debería basarse en un momento objetivo de entrada en un sistema informático (por ejemplo, el momento en que una comunicación se presenta a la plataforma ODR), o si una comunicación debería tenerse por recibida a partir del momento en que el destinatario pueda recuperarla.

Si se tuviera en cuenta esa última posibilidad:

i) y si se presume esa capacidad de recuperación cuando el proveedor de servicios ODR haya notificado a las partes pertinentes que dispone de la comunicación en la plataforma, ¿tiene lugar la recepción de hecho en el momento en que el proveedor de servicios ODR hace esa notificación? (véase también la opción 2, enunciada en los párrafos 34 y 35 *infra*);

ii) ¿Cuándo se rebate la presunción? En situaciones en que, por ejemplo, una parte (un consumidor) está de vacaciones y durante dos semanas no comprueba si ha recibido correos electrónicos, o si una parte (un consumidor) no actualiza su dirección electrónica y utiliza una cuenta antigua o inactiva como dirección de contacto, ¿podrá recuperarse la comunicación enviada a tal dirección? ¿Puede mantenerse la presunción a pesar de esas posibles situaciones prácticas? Si existe ambigüedad respecto de la capacidad de recepción, habrá también ambigüedad acerca del momento de la recepción, en cuyo caso el procedimiento ODR puede verse perturbado;

iii) Si el procedimiento ODR no ha llegado aún a la etapa en que se nombra al tercero neutral, ¿quién determina si hay que rebatir la presunción de que existe capacidad de recepción de una comunicación?

33. A fin de tener en cuenta una observación formulada en su 25º período de sesiones, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si la frase final entre corchetes, de acuerdo con el texto (actualmente entre corchetes) del párrafo 5) del proyecto de artículo 7 (Poderes del tercero neutral) es suficiente para regular las situaciones en que una de las partes, en particular un demandado que sea un consumidor, por la razón que fuera no haya podido recuperar una comunicación disponible en la plataforma.

Opción 2

34. En el último período de sesiones se sugirió que se volviera a redactar el párrafo 4) para que reflejara el párrafo 5 del artículo 2 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI⁸. Por consiguiente, se ha insertado la opción 2, que prevé la

⁸ El párrafo 5 del artículo 2 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI dice lo siguiente:
“La notificación se considerará recibida el día que haya sido entregada de conformidad con

comunicación “considerada recibida”, con lo cual se evita la idea de “cuándo una comunicación puede ser recuperada” y toda presunción al respecto. El texto propuesto presume que la recepción se produce en el momento en que el proveedor de servicios ODR notifica a las partes que la comunicación pertinente está disponible en la plataforma. Si bien una disposición en la que se considera recibida la comunicación puede trasladar a las partes un riesgo ligeramente superior de no recepción de la comunicación, en comparación con una disposición en la que se presuma la recepción (dado que la presunción puede rebatirse), puede también ofrecer una mayor certeza temporal. No obstante, los resultados de la opción 1 y de la opción 2 no son necesariamente diferentes; véase el párrafo 32 i) *supra*.

35. En la opción 2 se prevé también actualmente, entre corchetes, el poder discrecional del tercero neutral de prorrogar los plazos, cuando el destinatario demuestre que haya alguna buena razón por la que no haya podido recuperar esa comunicación en la plataforma.

2. Apertura del procedimiento

36. Proyecto de artículo 4A (Aviso)

“1. El demandante [enviará al proveedor de servicios ODR] [transmitirá a la plataforma ODR] un aviso con arreglo al formulario que figura en el párrafo 4). En lo posible deberá adjuntarse a dicho aviso todo documento u otra prueba en los que el demandante funde su reclamación, o deberá hacerse referencia a ellos.

2. [El proveedor de servicios ODR deberá comunicar [rápidamente] [sin demora] el aviso al demandado]. [El proveedor de servicios ODR notificará [rápidamente] [sin demora] al demandado que el aviso está disponible en la plataforma ODR.]

3. El procedimiento por vía ODR se tendrá por iniciado en la fecha de [recepción por el proveedor de servicios ODR en] [transmisión a] la plataforma ODR del aviso mencionado en el párrafo 1).

4. El aviso deberá contener:

a) el nombre y la dirección electrónica designada del demandante y (de haberse nombrado uno) del representante autorizado por el demandante para actuar en su nombre en el curso del procedimiento ODR;

b) el nombre y la dirección electrónica del demandado y (de haberse nombrado uno) del representante del demandado, siempre que el demandante conozca estos datos;

c) los motivos alegados como fundamento de la reclamación presentada;

d) cualquier solución que se proponga para resolver la controversia;

los párrafos 2, 3 o 4, o que se haya intentado entregar de conformidad con el párrafo 4. La notificación transmitida por medios electrónicos se considerará que ha sido recibida el día en que se envió, excepto si se trata de la notificación de arbitraje, en cuyo caso se considerará que ha sido recibida únicamente el día que se recibe en la dirección electrónica del destinatario”.

e) una declaración por la que el demandante acceda a participar en un procedimiento tramitado por vía ODR [o, en su caso, una declaración en el sentido de que las partes han convenido en recurrir a un procedimiento ODR en caso de que surja una controversia entre ellas];

f) una declaración por la que el demandante asegure no haber entablado un procedimiento por ninguna otra vía contra el demandado respecto de la controversia originada por la operación controvertida;

g) la ubicación del demandante;

[h) el idioma preferido para las actuaciones;]

i) la firma, en forma electrónica, del demandante y/o del representante del demandante, inclusive cualquier otro método de identificación y de autenticación;

[...]”

Observaciones

Observaciones generales

37. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la conveniencia de trasladar los proyectos de artículo 4A y 4B, relativos a la apertura del procedimiento, anteponiéndolos al actual proyecto de artículo 3, relativo a las comunicaciones, a fin de establecer en el reglamento una cronología que se ajuste más a la cronología presumible de las actuaciones.

38. En su 25º período de sesiones, el Grupo de Trabajo convino en que el proyecto de artículo 4 se dividiera en dos artículos separados, relativos al aviso y a la contestación, respectivamente. Además, el Grupo de Trabajo convino en incorporar los textos de los anexos existentes, en forma de párrafos, a los respectivos artículos (A/CN.9/744, párr. 76). Así pues, el antiguo anexo A figura ahora como párrafo 4) del proyecto de artículo 4A, y el antiguo anexo B figura como párrafo 3) del proyecto de artículo 4B.

39. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar sus deliberaciones y la sugerencia de declarar aplicables a este tipo de controversias principios de equidad, códigos de conducta, reglamentos generales uniformes u otras reglas sustantivas de equidad como base para decidir los casos (A/CN.9/716, párr. 101). Además de los párrafos 10 a 14 del documento A/CN.9/WG.III/WP.113 y de la Sección IV B) del documento A/CN.9/WG.III/WP.115, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la propuesta de adoptar un enfoque consistente en enumerar, en el párrafo 4) del proyecto de artículo 4A y en el párrafo 3) del proyecto de artículo 4B, una lista de posibles demandas y contestaciones a las mismas para incluir en el aviso y en la contestación, respectivamente.

40. Se han insertado palabras entre corchetes en el primer párrafo de los proyectos de artículo 4A y 4B, para el caso en que el Grupo de Trabajo deseara seguir el texto enunciado en el párrafo 1) del proyecto de artículo 3, en virtud del cual el aviso y la contestación se presentan en primer lugar en la plataforma ODR (véase, por ejemplo, el párrafo 25 *supra*).

Párrafo 2)

41. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si el proveedor de servicios ODR comunicará directamente el aviso al demandado o si le notificará la existencia del aviso en la plataforma ODR. Dado que esta última opción puede resultar más coherente con la forma de comunicación enunciada en el proyecto de artículo 3, se ha agregado al texto una segunda frase entre corchetes para prever esa opción.

Párrafo 3)

42. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la simplificación de este párrafo de modo que el criterio temporal se base en el momento de la recepción de la comunicación en la plataforma ODR, y no en el momento de recepción por el proveedor de servicios ODR, pues esta última posibilidad podría resultar menos transparente.

43. Se sugirió que se estudiara la inclusión de opciones con el fin de prever definiciones de apertura para cada fase concreta del procedimiento ODR: la negociación, la solución facilitada y el arbitraje (véase A/CN.9/WG.III/WP.112, párrs. 32 y 33).

*Párrafo 4) (anteriormente anexo A)**Párrafo 4), apartados c) y d)*

44. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si en el proyecto de párrafo 4) deberían enumerarse los motivos que podrán dar lugar a una reclamación y los remedios disponibles (A/CN.9/WG.III/WP.112, párr. 36; véase también A/CN.9/WG.III/WP.115, sección IV B)). En un contexto mundial y transfronterizo con reclamaciones relativas a un gran número de operaciones de poco valor, tal vez deban limitarse los casos a las simples demandas basadas en hechos y a los remedios básicos, a fin de no sobrecargar el sistema con casos complejos que le resten eficacia y lo encarezcan.

Párrafo 4), apartado f)

45. El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que, en su 23º período de sesiones, se estimó que el apartado f) del párrafo 4), junto con la disposición homóloga del párrafo 3) del proyecto de artículo 4B, tal vez podrían contribuir a impedir una multiplicidad de procedimientos relacionados con la misma controversia (véase A/CN.9/721, párr. 122).

Párrafo 4), apartado h)

46. En aras de la eficacia del procedimiento, el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de pedir a las partes que elijan el idioma en que prefieran que se tramite el procedimiento, en caso de que deseen utilizar un idioma distinto del utilizado al negociar la operación en litigio (véase A/CN.9/WG.III/WP.112/Add.1, párrs. 20 a 25).

Párrafo 4), apartado i)

47. El Grupo de Trabajo quizá desee recordar su debate acerca de que tal vez no fuese necesario utilizar métodos complejos de identificación y autenticación a los fines de la ODR, y que en los actuales textos de la CNUDMI sobre el comercio

electrónico ya se contemplaban métodos de firma electrónica que eran fiables y adecuados a los fines para los que se utilizaban (artículo 7 2) b) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico; véase A/CN.9/716, párr. 49). Tal vez sería más apropiado abordar la identificación y la autenticación de las partes en procedimientos ODR en un documento que no fuese el Reglamento, como las directrices y normas mínimas para los proveedores de servicios ODR. Conviene señalar también que el concepto de “firma electrónica” difiere del de “firma digital”. La firma electrónica⁹ designa a todo tipo de firmas que sirvan para identificar y autenticar al usuario, inclusive la gestión de los datos de identidad¹⁰.

48. Proyecto de artículo 4B (Contestación)

“1. El demandado [dará al proveedor de servicios ODR] [transmitirá a la plataforma ODR] su contestación al aviso mediante el formulario consignado en el párrafo 3) dentro de los [siete (7)] días de calendario siguientes a la fecha de recepción del aviso. El demandado deberá adjuntar a su contestación, en lo posible, cualquier documento u otra prueba en la que funde su defensa, o deberá hacer referencia a ellos.

[2.

[Opción 1: El demandado, en respuesta al aviso [comunicado por el demandante], podrá [comunicar] [presentar] una demanda derivada de la misma operación [o de las mismas circunstancias] señalada por el demandante en el aviso [al mismo proveedor de servicios ODR] [a la plataforma ODR] (“la contrademanda”).] La contrademanda deberá [transmitirse] [abrirse] a más tardar [siete (7)] días de calendario [después de que el aviso de la primera demanda haya sido [transmitido a la plataforma ODR] [comunicado al] [recibido por el] demandado]. [La contrademanda será dirimida en el procedimiento ODR junto con [la primera demanda] [el aviso del demandante].]

[En la contrademanda deberá indicarse la información mencionada en los apartados c) y d) del párrafo 4) del artículo 4A].]

[Opción 2: “El demandado, en respuesta al aviso, podrá transmitir una contrademanda a la plataforma. Por ‘contramanda’ se entenderá una demanda [independiente] formulada por el demandado contra el demandante basada en la misma operación o en las mismas circunstancias indicadas por el

⁹ En el apartado a) del artículo 2 de la Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas se define la firma electrónica como “los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos y para indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos”. En las firmas digitales se suelen emplear tecnologías criptográficas como la infraestructura de clave pública, que, para ser eficaz, requiere tecnologías y medios de aplicación específicos.

¹⁰ La gestión de los datos de identidad podría definirse como un sistema de procedimientos, políticas y tecnologías encaminado a gestionar el período de validez y los derechos de los usuarios y sus credenciales electrónicas. Se explicó que la verificación de la identidad de una persona o entidad que trate de entrar a distancia en un sistema, que tenga la autoría de una comunicación electrónica, o que firme un documento electrónico, entraba en el ámbito de lo que ha venido denominándose la “gestión de los datos de identidad”. Las funciones de la gestión de los datos de identidad se cumplen mediante tres procesos: la identificación, la autenticación y la autorización (véase A/CN.9/692 y A/CN.9/728).

demandante en el aviso [y dirigida al mismo proveedor de servicios ODR]”.] La contrademanda deberá [transmitirse] [abrirse] a más tardar [siete (7)] días de calendario [después de que el aviso de la primera demanda haya sido [transmitido a la plataforma ODR] [comunicado al] [recibido por el] demandado]. [La contrademanda será dirimida por el procedimiento ODR junto con [la primera demanda] [el aviso del demandante].

[En la contrademanda deberá indicarse la información mencionada en los apartados c) y d) del párrafo 4) del artículo 4A].]”]

3. *La contestación deberá contener:*

a) el nombre y la dirección electrónica designada del demandado y (de haberse nombrado uno) del representante autorizado por el demandado para actuar en su nombre en el curso del procedimiento ODR;

b) la contestación a la demanda y a los alegatos formulados en el aviso;

c) cualquier solución que se proponga para resolver la controversia;

[d) una declaración por la que el demandado acceda a participar en un procedimiento tramitado por la vía ODR];

e) una declaración por la que el demandado asegure no haber entablado un procedimiento por ninguna otra vía contra el demandante respecto de la controversia originada por la operación controvertida;

f) la ubicación del demandado;

[g) el idioma preferido para las actuaciones;]

h) la firma, en forma electrónica, del demandado y/o del representante del demandado, inclusive cualquier otro método de identificación y de autenticación;

[...]”

Observaciones

Observaciones generales

49. Tal como se señaló en los párrafos 25 y 40 *supra*, el Grupo de Trabajo tal vez desee plantearse una ligera modificación del texto de este artículo, a fin de que el idioma de transmisión de las comunicaciones a la plataforma ODR sea uniforme en todo el Reglamento.

Párrafo 1)

50. En su 24º período de sesiones, el Grupo de Trabajo convino en mantener en todo el Reglamento la expresión “de calendario” (A/CN.9/739, párr. 64). El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que los textos de la CNUDMI no contienen ninguna definición del concepto de “días de calendario”¹¹.

¹¹ No obstante, el artículo 2.6 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI trata de la prórroga de los plazos cuando el último día coincide con un feriado oficial o un día inhábil y en él se establece que los feriados oficiales o días inhábiles que tengan lugar durante el plazo se incluyen en el cálculo de dicho plazo.

51. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar su decisión de estipular en un documento adicional la recomendación de que en el Reglamento los plazos han de entenderse de manera liberal para garantizar la equidad para ambas partes, y de que el proveedor de servicios ODR puede establecer sus propias reglas con respecto a los plazos, siempre que no sean incompatibles con el Reglamento (A/CN.9/721, párr. 99). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si esas cuestiones han de abordarse en el Reglamento junto con las cuestiones pertinentes acerca del método por el que se habrá de calcular el plazo que se fije en el Reglamento y si debería dejarse que el proveedor de servicios ODR calculara ese plazo y reflejarlo en las directrices y los requisitos mínimos para los proveedores de servicios ODR.

Párrafo 2)

52. El párrafo 2) del proyecto de artículo 4B (anteriormente proyecto de artículo 4, párrafo 5)), refleja la decisión del Grupo de Trabajo de incluir en el Reglamento una disposición que rija las contrademandas (A/CN.9/739, párr. 93).

53. En su 24º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara una definición de “contrademanda”, como variante de lo propuesto en la opción 1, y que además sugiriera en qué lugar del Reglamento habría que insertar esa definición (A/CN.9/739, párr. 93). Por consiguiente, se ha insertado la opción 2 entre corchetes. El Grupo de Trabajo tal vez desee mantener en el texto la definición independiente propuesta en la opción 2 de este párrafo, o bien insertarla, por separado, en el proyecto de artículo 2 (Definiciones).

54. El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que se plantean varias cuestiones en relación con las contrademandas:

a) ¿Debe el demandado presentar una nueva demanda o incluir la contrademanda en su contestación? ¿Puede presumirse que la contestación al aviso ha de contener cualquier posible contrademanda? ¿Debe dejarse ese extremo claro al demandante, por ejemplo, requiriendo al demandado que así lo indique marcando una casilla separada? ¿Tendrá el tercero neutral discreción para decidir que una contestación incluye o constituye una contrademanda en ausencia de una declaración explícita del demandado a ese efecto? ¿Debe presentarse la contrademanda de la misma forma que la demanda inicial, especificada en el párrafo 4) del artículo 4A?

b) ¿Tendrá el demandante ocasión de contestar a la contrademanda o tendrá el tercero neutral discreción para solicitar al demandante que lo haga?

c) ¿Cómo se determinará si la contrademanda entra en el ámbito de la demanda inicial enunciada en el aviso del demandante? (A/CN.9/739, párr. 92). El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar en qué medida se aborda esa cuestión en el proyecto de artículo 7 y, en particular, en el párrafo 4) del mismo (facultad del tercero neutral para dictaminar acerca de su propia competencia jurisdiccional, inclusive sobre la existencia o la validez del acuerdo para someter la controversia a un procedimiento ODR).

d) ¿Deben regularse en el Reglamento o en algún documento adicional los motivos para decidir si una contrademanda entra en el ámbito de la demanda inicial?

e) ¿La presentación de una contrademanda impide al demandado presentar una nueva demanda sobre la misma operación a otro proveedor de servicios ODR?

Párrafo 3)

55. El párrafo 3) regula el contenido de la contestación al aviso y refleja las disposiciones del párrafo 4) del proyecto de artículo 4A.

Párrafo 3), apartado a)

56. Al igual que en el párrafo 4) del proyecto de artículo 4A, habría que tomar en consideración el tema de la protección de los datos o de la vida privada y de la seguridad de los medios informáticos en el contexto de la comunicación de información relativa a las partes durante un procedimiento ODR (A/CN.9/721, párr. 108).

Párrafo 3), apartados b) y c)

57. Los apartados b) y c) de párrafo 3 reflejan los apartados c) y d) del párrafo 4) del proyecto de artículo 4A. En cuanto a la disposición homóloga del proyecto de artículo 4A, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si en el párrafo 3) del proyecto de artículo 4B deberían enumerarse las contestaciones a las declaraciones, a los alegatos y a las soluciones propuestas en el aviso.

Párrafo 3), apartado d)

58. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si esta disposición es necesaria, habida cuenta del acuerdo que ya conciertan ambas partes en el momento de la operación (véanse los párrafos 12 a 14 *supra*).

Párrafo 3), apartados e) a h)

59. Para los apartados e) a h) del párrafo 3) cabe remitirse a las deliberaciones mantenidas respecto de los apartados f) a i) del párrafo 4) del artículo 4A.

(A/CN.9/WG.III/WP.117/Add.1) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 26º período de sesiones

ADICIÓN

Índice

	<i>Párrafos</i>
B. Notas sobre el proyecto de reglamento (<i>continuación</i>)	1-65
3. Negociación	1-15
4. Tercero neutral	16-34
5. Arreglo facilitado y arbitraje	35-43
6. Decisión del tercero neutral	44-52
7. Otras disposiciones	53-65

B. Notas sobre el proyecto de reglamento (*continuación*)**3. Negociación****1. Proyecto de artículo 5 (Negociación y arreglo)***[Negociación]*

“1. *[Tras la [presentación] [recepción] de la contestación [y, si procede, de la contrademanda] [[a][en] la plataforma ODR] [y de la notificación de esta al demandante] a que se hace referencia en el artículo [4B, párrafo[s] 1) y [2)]]], las partes tratarán de resolver su controversia mediante negociaciones directas, incluso, en su caso, mediante los métodos de comunicación que ofrezca la plataforma ODR.]*

2. *Si el demandado no [da al proveedor de servicios ODR su contestación al aviso mediante el formulario consignado en el artículo 4B, párrafo 3)] [contestar al aviso] en un plazo de siete (7) días de calendario, se presumirá que ha rechazado la invitación a negociar y el procedimiento ODR pasará automáticamente a la[s] [siguiente(s)] etapa[s] [del arreglo facilitado [y del arbitraje]], en cuyo momento el proveedor de servicios ODR deberá proceder [rápidamente] [sin demora] al nombramiento de un tercero neutral con arreglo a lo previsto en el artículo 6 (Nombramiento de un tercero neutral).*

3. *Si las partes no han resuelto su controversia mediante la negociación en el plazo de diez (10) días de calendario contados a partir de la fecha de recepción de la contestación [por el proveedor de servicios ODR] [y de la notificación de esta al demandante], el procedimiento ODR pasará automáticamente a la[s] [siguiente(s)] etapa[s] [del arreglo facilitado [y del arbitraje]].*

4. Las partes podrán convenir en prorrogar una vez el plazo para [presentar la contestación] [llegar a un arreglo]. No obstante, dicha prórroga no podrá exceder de diez (10) días de calendario.

[Arreglo]

5. Si se llega a un arreglo [durante la etapa de negociación] [o en cualquier otra etapa del procedimiento ODR], [se consignarán las condiciones de ese arreglo en la plataforma ODR], [en cuyo momento,] [, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 6) del artículo 5,] se dará automáticamente por concluido el procedimiento ODR.

[6. Cuando una de las partes no haya puesto en práctica un arreglo alcanzado conforme a lo dispuesto en el párrafo 5) en el plazo de [diez (10)] días contados a partir de la fecha en que se haya llegado a ese arreglo [y de que este se haya consignado en la plataforma ODR] [(el “plazo máximo” (“long-stop date”), cualquiera de las partes podrá [reiniciar] [reabrir] el procedimiento ODR [con el mismo proveedor de servicios ODR] [en un plazo de quince (15) días después de cumplirse el plazo máximo] para solicitar [una decisión] [un laudo] que refleje las condiciones del arreglo y que un tercero neutral estará facultado para dictar.]”

Observaciones generales

2. La Secretaría ha cambiado el orden de los párrafos del proyecto de artículo 5, teniendo en cuenta las propuestas del Grupo de Trabajo y con miras a reflejar más claramente la cronología probable de las negociaciones y el arreglo o acuerdo. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de incorporar los subencabezamientos provisionales insertados en este artículo para distinguir mejor entre las etapas de negociación y de arreglo, en particular si se inclina a considerar que el arreglo es un proceso que puede tener lugar en cualquier momento durante el curso del procedimiento, incluso en las etapas del arreglo facilitado y de arbitraje (sin embargo, véase A/CN.9/744, párrafo 85).

3. El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que la etapa de negociación puede consistir en negociación asistida, en negociación automatizada o en ambas. En la primera, las partes procuran llegar a una solución comunicándose por los medios electrónicos que ofrece el proveedor de servicios ODR. En la segunda, cada parte propone una solución, a la controversia, generalmente expresada en valores monetarios, que no se comunica a la otra parte. A continuación, el programa informático compara las ofertas y procura determinar una solución satisfactoria para ambas partes si las ofertas están dentro de un margen determinado. Tal vez en el Reglamento se deba tomar en consideración la utilización de negociación automatizada cuando sea la tecnología (el programa informático) la que “negocie” el arreglo sobre la base de las propuestas presentadas por las partes. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la posibilidad de que en las disposiciones relativas a la negociación se incluyeran la negociación asistida y la negociación automatizada.

Párrafo 1)

4. En su 25º período de sesiones el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que modificara la redacción del párrafo 1) a fin de tener en cuenta las propuestas de que se definiera con más claridad la etapa de negociación y, además, de que el

Reglamento apoyara la aplicación de soluciones negociadas (A/CN.9/744, párrafos 79 a 81). En consecuencia, en el párrafo 1) se abordan ahora el momento y el contenido de la etapa de negociación. En ese párrafo anteriormente se preveían las consecuencias del arreglo (a saber, la conclusión del procedimiento), que ahora figuran en el proyecto de párrafo 5).

Párrafo 2)

5. Se insertó el siguiente texto propuesto “[dar al proveedor de servicios ODR su contestación al aviso mediante el formulario consignado en el artículo 4B del párrafo 3)]”, para sustituir la frase “[contesta al aviso]” y hacerla compatible con los requisitos del aviso establecidos en el párrafo 4) del artículo 4B, así como también para evitar ambigüedades en relación con el momento de la recepción.

6. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar su decisión en el sentido de que, en caso de fracasar las negociaciones, se pasaría automáticamente a la siguiente etapa (A/CN.9/739, párrafo 97). Al definir esa segunda etapa (la segunda variante que figura entre corchetes), el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la posibilidad de que para las tres etapas concretas previstas del procedimiento ODR -la negociación, el arreglo facilitado y el arbitraje- haya definiciones de la apertura separadas y diferenciadas (véase A/CN.9/WG.III/WP.112, párrafo 33).

Párrafo 3)

7. El texto entre corchetes se incorporó para aclarar el momento de la recepción de la contestación y en aras de la uniformidad con las demás disposiciones de este artículo.

Párrafo 4)

8. En el 25º período de sesiones del Grupo de Trabajo se señaló que sería preferible limitar el período durante el cual pudiera acordarse una prórroga con miras a reforzar la eficiencia del procedimiento; se convino en que bastaría con un plazo de diez días (A/CN.9/744, párrafos 84 y 86).

9. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si la intención de este párrafo es prorrogar el plazo para presentar una contestación (conforme al párrafo 3) del proyecto de artículo 4), o para llegar a un arreglo (conforme al párrafo 5) del proyecto de artículo 5). Aunque esas opciones no son mutuamente excluyentes, el Grupo de Trabajo tal vez desee recordar el consenso a que había llegado en el sentido de que solo habría que emplear una de esas variantes (A/CN.9/744, párrafo 85). Se deliberó acerca de la posibilidad de que el párrafo rigiera únicamente la apertura del procedimiento y, por consiguiente, se aplicara únicamente a la contestación, o de que, por el contrario, restringiera la posibilidad de que las partes negociaran mediante el sistema ODR limitando el plazo en que pudieran llegar a un acuerdo mediante esas negociaciones (sin perjuicio de su posibilidad de negociar, en cualquier caso, al margen del sistema ODR).

Párrafo 5)

10. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar la preferencia expresada en el sentido de que los arreglos quedaran claramente consignados en la plataforma ODR (A/CN.9/744, párrafo 90). Tal vez desee considerar la posibilidad de llegar a un

arreglo en cualquier etapa del procedimiento ODR y la conveniencia de consignar todo arreglo de ese tipo en la plataforma ODR. Si el Grupo de Trabajo decide adoptar un enfoque por el cual pueda llegarse a un arreglo en distintos momentos del procedimiento ODR, es posible que desee considerar si ese arreglo se debería incorporar en un proyecto de artículo separado, a fin de distinguir su carácter independiente del proceso de negociación.

11. Además, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar los aspectos técnicos relativos a la formación de los acuerdos de solución, entre otras cosas, si estos exigirían una disposición separada que previera las controversias planteadas a raíz del arreglo.

Párrafo 6)

12. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar el acuerdo a que había llegado en el sentido de que el objetivo de este párrafo era permitir que una parte reabriera el procedimiento con el único objetivo de obtener un laudo o una decisión que le permitiera solicitar la ejecución (A/CN.9/744, párrafo 90).

13. En particular, tal vez el Grupo de Trabajo desee recordar las cuestiones siguientes, planteadas durante el 25º período de sesiones, que pueden ser aplicadas a una disposición sobre el incumplimiento (A/CN.9/744, párrafo 90): i) la relación entre este párrafo y el (actual) párrafo 5) con respecto al arreglo; ii) el hecho de que el establecimiento de plazos breves para el cumplimiento del arreglo o la reapertura podría alentar a la parte pertinente a cumplirlo; iii) el hecho de que el término “reabrir” da una mejor idea del sentido del párrafo que el término “reiniciar”, ya que la intención no era iniciar todo el procedimiento ODR desde la etapa de la demanda y el aviso; iv) la posibilidad de que los proveedores de servicios ODR buscaran el foro más favorable, si en el párrafo no se aclaraba que se debía recurrir al mismo proveedor; y v) la necesidad de que los arreglos quedaran claramente consignados en la plataforma ODR.

14. Tal vez el Grupo de Trabajo también desee examinar los aspectos prácticos de la reapertura del procedimiento, y si en el Reglamento se deben aclarar las siguientes cuestiones: i) si se nombraría a un nuevo tercero neutral que sustituyera al anterior, o se esperaría que el tercero neutral anterior volviera a asumir sus funciones; y ii) si se debería hacer referencia al proyecto de artículo 9 a fin de aclarar los plazos para emitir un laudo o una decisión.

15. Se insertó un texto entre corchetes, por si el Grupo de Trabajo desea examinar la posibilidad de imponer un plazo a la parte interesada en reabrir el procedimiento tras el presunto incumplimiento de un acuerdo de solución.

4. Tercero neutral

16. Proyecto de artículo 6 (Nombramiento de un tercero neutral)

“1. El proveedor de servicios ODR a través de la plataforma ODR nombrará a un tercero neutral seleccionado de una lista de terceros neutrales cualificados que deberá llevar el proveedor de servicios ODR [o que provenga de otras instituciones arbitrales]. Una vez nombrado el tercero neutral, el proveedor de servicios ODR deberá notificar ese nombramiento a las partes.

[2. Se considerará que todo tercero neutral, al aceptar su nombramiento, se compromete a dedicar el tiempo suficiente al procedimiento ODR para cumplirlo sin dilación y conforme al Reglamento.]

3. El tercero neutral declarará su independencia y deberá dar a conocer al proveedor de servicios ODR toda circunstancia [que se plantee en cualquier momento en el curso del procedimiento ODR] que pueda suscitar dudas fundadas acerca de su imparcialidad o de su independencia. El proveedor de servicios ODR deberá comunicar esa información a las partes.

4. Toda parte podrá impugnar el nombramiento del tercero neutral dentro de los [dos (2)] días de calendario siguientes al [i)] al aviso del nombramiento [sin indicar los motivos] [; o ii) a haberse enterado de un hecho o asunto que pueda suscitar dudas fundadas sobre la imparcialidad o la independencia del tercero neutral, [siempre y cuando esa parte señale el hecho o el asunto que ha suscitado esas dudas,] en cualquier momento en el curso del procedimiento ODR].

4 bis. Cuando una parte se oponga al nombramiento de un tercero neutral, ese tercero neutral quedará automáticamente descalificado y el proveedor de servicios ODR nombrará a otro en su lugar. Cada una de las partes podrá oponerse [tres (3)] veces, como máximo, al nombramiento de un tercero neutral tras recibir cada aviso de su nombramiento [con arreglo a lo dispuesto en [i)/[i) o ii)]] supra, después de lo cual el nombramiento del tercero neutral por el proveedor de servicios ODR será definitivo [, a reserva de lo dispuesto en el artículo 4 ii) supra]. [Por otra parte, si no se presentan objeciones dentro de los dos (2) días siguientes al aviso del nombramiento, este será definitivo, a reserva de lo dispuesto en ii) supra.]

5. Cada una de las partes podrá expresar sus reparos, en el plazo de tres (3) días de calendario contados a partir del nombramiento definitivo del tercero neutral, a que el proveedor de servicios ODR suministre a ese tercero neutral información generada durante la etapa de negociación [salvo en la situación a que se aplica el artículo 5(6)]. Tras cumplirse ese plazo de tres días, y si no hay objeciones, el proveedor de servicios ODR transmitirá al tercero neutral toda la información existente en la plataforma ODR.

6. Si se ha de sustituir a un tercero neutral en el curso del procedimiento ODR, el proveedor de servicios ODR, a través de la plataforma ODR, procederá nombrar a otro tercero neutral que lo sustituya y a notificar a las partes el nombramiento [rápidamente] [sin dilación]. El procedimiento ODR se reanudará a partir del momento en que el tercero neutral sustituido haya dejado de cumplir sus funciones.

7. Solamente habrá un tercero neutral, salvo que las partes decidan otra cosa.”

Observaciones

Párrafo 1)

17. Se sugirió incluir el texto entre corchetes que figura al final de la primera oración a fin de facilitar el acceso a un mayor número de terceros neutrales, incluso a los que provengan de instituciones arbitrales (A/CN.9/744, párrafo 103).

18. El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que la segunda oración se trasladó del párrafo 4) original (actual párrafo 5)) a fin de aclarar la cronología de la comunicación del nombramiento de un tercero neutral a las partes.

Párrafo 2)

19. El párrafo 2) del proyecto de artículo 6 se trasladó desde el párrafo 1) del proyecto de artículo 7, al haber determinado el Grupo de Trabajo que ese párrafo guardaba una mayor relación con el nombramiento del tercero neutral (A/CN.9/744, párrafo 104).

Párrafo 3)

20. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar la sugerencia de dar la idea de que la obligación de independencia e imparcialidad del tercero neutral sea de carácter permanente (A/CN.9/744, párrafo 92). Esa obligación se refleja también en el actual proyecto de artículo 7, párrafo 1) *bis*.

Párrafos 4) y 4) bis.

21. En su 25º período de sesiones el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que en el proyecto de artículo 6 redactara una disposición por separado en virtud de la cual una parte pudiera oponerse al nombramiento de un tercero neutral en cualquier etapa del procedimiento, siempre y cuando esa objeción estuviera justificada (A/CN.9/744, párrafo 94). En consecuencia, el antiguo párrafo 3) se dividió en dos párrafos, 4) y 4) *bis*, para diferenciar entre el derecho de una parte a impugnar el nombramiento de un tercero neutral en cualquier momento y las consecuencias de esa impugnación.

22. El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que el actual texto entre corchetes del párrafo 4) permite a una parte impugnar el nombramiento del tercero neutral hasta dos días después de haberse enterado de un hecho o asunto que justifique su impugnación, si bien en cualquier momento en el curso del procedimiento ODR. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar i) si la parte impugnadora debería demostrar objetivamente la existencia de ese hecho o asunto justificatorio (véase el documento A/CN.9/744, párrafo 94, así como el texto relativo a la obligación permanente de informar impuesta al tercero neutral en el proyecto de artículo 6, párrafo 3)); y ii) si el tercero neutral de que se tratase estaría facultado para decidir sobre su propia competencia respecto de esa impugnación (teniendo presente la actual disposición sobre la propia competencia que figura en el artículo 7 4)).

23. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si el número máximo de impugnaciones (actualmente tres) se aplicaría tanto al nombramiento del primer tercero neutral (respecto del cual las partes no necesitan invocar motivos fundados para la impugnación), como al tercero neutral nombrado para sustituirlo, después de que una parte justificara objetivamente su impugnación. El actual texto que figura entre corchetes da la opción de que el número máximo de impugnaciones se aplique únicamente al primer caso o a ambos.

Párrafo 5)

24. El párrafo 5) (antiguo párrafo 4)) se enmendó a fin de reflejar el principio de que las partes dispondrían de un plazo de tres días para oponerse a la entrega

de información al tercero neutral, pero que, una vez expirado ese plazo, toda la información se haría llegar al tercero neutral (A/CN.9/744, párrafo 97).

Párrafo 7)

25. En su 25º período de sesiones el Grupo de Trabajo convino en mantener la redacción de este párrafo, ya que resultaba claro y permitía cierto grado de flexibilidad (A/CN.9/744, párrafos 101 y 102).

26. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si ubicar este párrafo inmediatamente después del párrafo 1) serviría para establecer una cronología más lógica.

27. Proyecto de artículo 7 (Poderes del tercero neutral)

[“1. A reserva de lo dispuesto en el presente Reglamento [y en las directrices y requisitos mínimos para terceros neutrales en la vía ODR], el tercero neutral podrá dirigir el procedimiento ODR como lo estime oportuno.

1 bis. El tercero neutral en ejercicio [de su discrecionalidad] [de sus funciones previstas en el presente Reglamento], dirigirá el procedimiento ODR evitando demoras o gastos innecesarios y cumpliendo un proceso justo y eficiente para resolver el litigio. A esos efectos, el tercero neutral deberá mantenerse en todo momento totalmente independiente e imparcial y deberá tratar a las dos partes en pie de igualdad.]

2. A reserva de cualesquiera objeciones previstas en el artículo 6, párrafo 5) el tercero neutral dirigirá el procedimiento ODR sobre la base de los documentos presentados por las partes y de toda comunicación enviada por ellas al proveedor de servicios ODR, cuya importancia para el caso será determinada por el tercero neutral. El procedimiento ODR se sustanciará únicamente sobre la base de la documentación presentada, a menos que el tercero neutral decida otra cosa.

3. En todo momento durante el curso del procedimiento, el tercero neutral podrá [exigir] [pedir] o permitir a las partes (conforme a las condiciones en materia de costas y otros gastos que el tercero neutral determine) que facilite datos suplementarios, o que presente otros documentos o pruebas, dentro del plazo que determine el tercero neutral.

4. El tercero neutral estará facultado para dictaminar acerca de su propia competencia jurisdiccional y respecto de toda objeción que le sea presentada acerca de la existencia o validez del acuerdo por el que la controversia haya sido remitida a la vía ODR. Para ese fin, se entenderá que toda cláusula para el arreglo de controversias que forme parte de un contrato constituye un acuerdo independiente de las demás condiciones del mencionado contrato. [Una decisión] [un laudo] por [la] [el] que el tercero neutral dictamine la nulidad de dicho contrato no supondrá automáticamente que la cláusula para la solución de la controversia sea, a su vez, inválida.

[5. Cuando el tercero neutral considere que puede haber dudas de que el demandado haya recibido el aviso conforme al Reglamento, hará las averiguaciones o adoptará las medidas que considere necesarias para

cerciorarse de que lo haya recibido y, con ese fin, podrá ampliar todo plazo establecido en el Reglamento, si lo considera necesario;

- i) [de que alguna de las partes haya recibido cualquier otra comunicación en el curso del procedimiento ODR, el tercero neutral podrá hacer las averiguaciones o adoptar las medidas que considere necesarias para cerciorarse de que la haya recibido, y con ese fin, podrá ampliar todo plazo establecido en el Reglamento, si lo considera necesario.]]”*

Observaciones

Párrafos 1) y 1 bis.

28. Este párrafo (el antiguo párrafo 2)) se dividió en los párrafos 1) y 1) *bis* y se reorganizó en cierta medida para caracterizar más claramente i) las funciones del tercero neutral; y ii) la discrecionalidad amplia del tercero neutral en lo que respecta a dirigir el procedimiento ODR como lo considere oportuno, a reserva de algunas restricciones (véase A/CN.9/744, párrafo 105).

29. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si en el párrafo 1) se debería incorporar expresamente un documento que se prepararía en relación con las directrices y los requisitos mínimos para los terceros neutrales (véase A/CN.9/WG.III/WP.114) como norma a la que debería estar sujeto el tercero neutral para dirigir el procedimiento.

30. Si bien la formulación del párrafo 1) *bis* refleja la del artículo 17 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, tal vez el Grupo de Trabajo desee examinar también si la palabra “funciones” sería más congruente con la formulación utilizada anteriormente en el artículo 6 6) del Reglamento.

Párrafo 2)

31. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar el acuerdo a que llegó en el sentido de que este párrafo debería estar supeditado a la posibilidad de una parte de oponerse a la entrega por el proveedor de servicios ODR al tercero neutral de la información generada durante la etapa de negociación del procedimiento ODR (A/CN.9/744, párrafo 108).

Párrafo 3)

32. Este párrafo se modificó ligeramente a fin de reflejar el interés del Grupo de Trabajo en que se conservara en el Reglamento el concepto de “carga de la prueba”, pero que, como era un principio sustantivo que entrañaba consecuencias y obligaciones jurídicas, se cambiara de lugar (A/CN.9/744, párrafos 110 a 112). En consecuencia, la disposición sobre la carga de la prueba se trasladó al proyecto de artículo 9, párrafo 6), *infra*.

33. Además, el Grupo de Trabajo tal vez desee recordar que había estudiado la posibilidad de modificar ligeramente las facultades del tercero neutral a fin de permitirle que solicitara, pero no exigiera, a las partes que facilitaran datos suplementarios (A/CN.9/744, párrafo 109).

Párrafo 5)

34. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar su solicitud a la Secretaría de que volviera a redactar este párrafo (antiguo párrafo 6)) a fin de i) obligar al tercero neutral a que hiciera averiguaciones cuando hubiera dudas sobre la recepción del aviso, y ii) conferir al tercero neutral la facultad de hacerlo respecto de todas las demás comunicaciones (A/CN.9/744, párrafos 115 a 117). El texto entre corchetes se insertó en respuesta a esa solicitud.

5. [Arreglo facilitado y arbitraje]**35. Proyecto de artículo 8 (Arreglo facilitado)**

“1. El tercero neutral deberá evaluar la controversia conforme a la información presentada y comunicarse con las partes para tratar de llegar a un acuerdo. Si las partes llegan a [un acuerdo] [un arreglo], [ese arreglo se consignará en la plataforma ODR], [en cuyo momento,] [sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 6).] el procedimiento ODR se dará automáticamente por concluido.

1 bis. Si las partes no llegan [a un acuerdo] [un arreglo] en el plazo de diez (10) días de calendario, [las partes tendrán la opción de pasar a la[s] etapa[s] siguiente[s] del procedimiento ODR] [el tercero neutral emitirá [una decisión] [un laudo] de conformidad con el artículo 9].

[2. Si, a raíz de su participación en el arreglo de la controversia, un tercero neutral llegara a abrigar dudas de si podría mantenerse imparcial o independiente durante el resto del procedimiento ODR de conformidad con el artículo 9, ese tercero neutral presentará su renuncia e informará en consecuencia a las partes y al proveedor de servicios ODR.]”

Observaciones generales

36. Se incluyó entre corchetes la palabra “arreglo” como variante de “acuerdo”, ya que puede considerarse más compatible con el texto del proyecto de artículo 5.

Párrafo 1)

37. El párrafo 1) se dividió en dos párrafos a fin de expresar con más claridad la cronología de un arreglo facilitado y de todo intento fallido de alcanzarlo.

38. En el párrafo 1) se insertó texto entre corchetes para reflejar el texto relativo al arreglo que figura en el párrafo 5) del proyecto de artículo 5. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la conveniencia de prever otra opción, que consistiera sencillamente en señalar que si se llegara a un arreglo se aplicarían las disposiciones correspondientes de los párrafos 5) y 6) del proyecto de artículo 5.

39. En particular, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar también si se debería aplicar a todo arreglo que surgiera en la etapa del arreglo facilitado una disposición relativa a la imposibilidad de poner en práctica un arreglo, paralela a la que figura en el artículo 5, párrafo 6).

Párrafo 1) bis.

40. El párrafo 1) *bis.* guarda estrecha relación con el proyecto de artículo 1, relativo al carácter gradual del procedimiento ODR, así como con el mecanismo previsto en los párrafos 2) y 3) del proyecto de artículo 5, relativos a la transición de la negociación a la etapa siguiente del procedimiento de arbitraje.

41. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar que este párrafo tiene por objeto determinar si, al no haberse llegado a un arreglo facilitado, las partes deberían tener la opción de determinar si el procedimiento pasaría a la etapa final, o si el paso hacia el laudo o la decisión sería automático (A/CN.9/744, párrafo 121).

42. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar que se había apoyado en cierta medida la idea de que era necesario un acuerdo o un requisito adicional para pasar a la etapa siguiente, ya que se consideraba que el momento en que se produjera esa aceptación equivaldría a un acuerdo para recurrir al arbitraje después de surgir una controversia (A/CN.9/744, párrafo 123; véase también el párrafo 14 del documento A/CN.9/WG.III/WP.117, relativo a la conveniencia de exigir una confirmación en esta etapa). Además, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si dictar automáticamente un laudo o una decisión en esta etapa podría desdibujar la distinción entre la etapa de arreglo facilitado y la de arbitraje, con las consiguientes dificultades para establecer un acuerdo “confirmatorio” para pasar a la etapa de arbitraje.

Párrafo 2)

43. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la conveniencia de incluir el párrafo 2) en el proyecto de artículo 8, o si sería mejor que estuviera en el proyecto de artículo 6, en particular el párrafo 3).

6. Decisión del tercero neutral

44. Proyecto de artículo 9 ([Emisión de] [Comunicación de] [una decisión] [un laudo])

“1. El tercero neutral deberá emitir [una decisión] [un laudo] [rápidamente] [sin dilación] y, en todo caso, dentro de los siete (7) días de calendario [con la posibilidad de una extensión de otros siete (7) días de calendario] a partir de la fecha en que las partes hayan presentado la documentación definitiva del caso al tercero neutral. El proveedor de servicios ODR comunicará su [decisión] [laudo] a las partes. El no haber observado este plazo no constituirá motivo para impugnar [la decisión emitida] [el laudo emitido].

2. [La decisión] [El laudo] deberá figurar por escrito y estar [firmada] [firmado] por el tercero neutral, con especificación de la fecha en que fue [emitida] [emitido] [y una breve descripción de los motivos de [la decisión] [el laudo]].

[3. [La decisión] [El laudo] será [definitiva] [definitivo] y vinculante para las partes. Las partes deberán cumplir [rápidamente] [la decisión] [el laudo] sin dilación.]

4. Dentro de los [cinco (5)] días de calendario siguientes a la recepción [de la decisión] [del laudo], toda parte podrá, previo aviso a la otra parte, solicitar al tercero neutral que rectifique en su [decisión] [laudo] todo error de cómputo, tipográfico o de copia [, o todo error u omisión de índole similar]. Si el tercero neutral considera que esa solicitud está justificada, efectuará la rectificación [, incluida una breve justificación de la misma,] dentro de los [dos (2)] días de calendario siguientes a la recepción de la solicitud. La rectificación [se hará por escrito y] formará parte [de la decisión] [del laudo].

5. En todos los casos, el tercero neutral deberá decidir con arreglo a las condiciones del contrato y habida cuenta de todo hecho o circunstancia que sea del caso [, y deberá tener en cuenta todo uso del comercio que sea aplicable a la operación].”

[6. Cada una de las partes asumirá la carga de probar todo hecho alegado en su demanda o en su contestación.]

Observaciones

Párrafo 1)

45. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si en el Reglamento se prevé un vínculo suficiente entre el arreglo facilitado y la etapa de la decisión, y también si se imparte suficiente orientación sobre el marco cronológico en que las partes deben presentar documentación (incluida la “documentación definitiva”) al tercero neutral.

46. El Grupo de Trabajo tal vez desee deliberar sobre la situación que se plantea cuando el tercero neutral no emite una decisión en el plazo previsto en el párrafo (A/CN.9/739, párrafo 133), y examinar la sugerencia de imponer sanciones basadas en la reputación a las partes en un procedimiento ODR que no cumplan sus obligaciones (A/CN.9/739, párrafo 136).

Párrafo 2)

47. El Grupo de Trabajo tal vez desee abordar la cuestión de si es preciso que un tercero neutral fundamente su decisión (A/CN.9/739, párrafo 137).

48. El requisito de que la decisión o el laudo figure por escrito y esté firmado por el tercero neutral refleja el texto del artículo 31 1) de la Ley Modelo sobre Arbitraje.

Párrafo 4)

49. El Grupo de Trabajo tal vez desee abordar la cuestión de si el tercero neutral debe expresar las razones que ha tenido para rectificar su decisión (A/CN.9/739, párrafo 139).

Párrafo 5)

50. El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que, como el párrafo 5 guarda relación con principios jurídicos sustantivos para resolver controversias, se sugirió suprimirlo del proyecto de artículo 9 e incluirlo en otra parte (A/CN.9/739, párrafo 141). El Grupo de Trabajo tal vez desee observar también que esa cuestión se aborda en el documento A/CN.9/WG.III/WP.113. Quizás desee estudiar la

posibilidad de trasladar este párrafo, así como el párrafo siguiente relativo a la carga de la prueba, a un anexo o documento separado relativo a los principios jurídicos sustantivos o las directrices para la solución de controversias por un tercero neutral mediante el procedimiento ODR.

Párrafo 6)

51. El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que, como el párrafo 6) (antiguo proyecto de artículo 7, párrafo 4)) se refiere a los principios jurídicos sustantivos para la solución de controversias, se sugirió trasladarlo del proyecto de artículo 7 a otra parte del Reglamento (A/CN.9/744, párrafo 112).

52. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si es necesario que en el Reglamento figure esa disposición. Además, quizás desee recordar la inquietud expresada en el sentido de que el enunciado actual de este párrafo no reflejaba los distintos conceptos que tenían los diversos Estados respecto de la carga de la prueba en los casos de reclamaciones de los consumidores (A/CN.9/744, párrafo 111).

7. Otras disposiciones

53. Proyecto de artículo 10 (Idioma de las actuaciones)

“[El procedimiento ODR será sustanciado en el idioma utilizado al negociar la operación en litigio, [salvo que las partes convengan en otro idioma] [salvo que el tercero neutral decida otra cosa]. [Si las partes no se ponen de acuerdo acerca del idioma del procedimiento, el tercero neutral deberá determinar el idioma que se utilizará.]]”

Observaciones

54. El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que, en algunas situaciones, el idioma empleado al negociarse una operación puede no ser el mismo para el vendedor y el comprador, según el lugar en que se encuentren. Por ejemplo, es posible que un vendedor solo pueda entrar en un sitio de venta empleando un idioma y que el sitio cambie automáticamente de idioma en función del protocolo Internet (IP) del comprador, el cual refleja su ubicación y el idioma comúnmente empleado en ese lugar. En tal caso, la determinación del “idioma empleado al negociarse una operación” podría resultar problemática.

55. Además, un argumento que frecuentemente se aduce en contra de que el idioma de la operación sea el idioma del procedimiento es que el nivel de comprensión de un idioma que se necesita para concertar una operación puede diferir del nivel necesario para hacer una reclamación. La tecnología puede ayudar a las partes a superar esos obstáculos lingüísticos, haciendo posible que los usuarios presenten una demanda sin conocer muy bien el idioma de la plataforma ODR. No obstante, deberá tenerse en cuenta que una plataforma ODR determinada podría no tener la capacidad de prestar esa clase de servicios basados en la tecnología, ni ofrecer la variedad completa de idiomas.

56. Para facilitar el acuerdo sobre el idioma del procedimiento, el Grupo de Trabajo tal vez desee incluir en los anexos A y B del proyecto de artículo 4 la posibilidad de que las partes elijan el idioma que prefieren utilizar (véase A/CN.9/WG.III/WP.112, párrafo 38).

57. El proyecto de artículo 10 refleja la sugerencia hecha por el Grupo de Trabajo en el sentido de que, cuando las partes no hayan llegado a un acuerdo sobre el idioma del procedimiento, esa cuestión se deje en manos del tercero neutral (A/CN.9/716, párrafo 105). En ese caso, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la forma de determinar el idioma del procedimiento antes de que intervenga el tercero neutral y la base sobre la cual este decidirá el idioma que se habrá de utilizar.

58. El Grupo de Trabajo tal vez desee observar también que en los casos en que el tercero neutral necesite examinar la documentación de apoyo presentada por las partes, el proveedor de servicios ODR tal vez deba nombrar a un tercero neutral que entienda el idioma o los idiomas pertinentes.

59. Se propuso que se insertara un nuevo párrafo del siguiente tenor (A/CN.9/739, párrafo 143): *“Todo proveedor de servicios ODR que tenga trato con partes que usen distintos idiomas se cerciorará de que su sistema, su Reglamento y los terceros neutrales tengan en cuenta esas diferencias y establecerá mecanismos para atender a las necesidades de las partes al respecto”*. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si sería mejor ubicar esa clase de referencia en las directrices y requisitos mínimos para los proveedores de servicios ODR.

60. Proyecto de artículo 11 (Representación)

“Toda parte podrá hacerse representar o asesorar por una o más personas seleccionadas por ella. Los nombres y las direcciones electrónicas de la persona o las personas seleccionadas [y el poder para actuar en nombre de la parte interesada] deberán ser comunicados a la otra parte por conducto del proveedor de servicios ODR.”

61. Proyecto de artículo 12 (Exclusión de responsabilidad)

“[Salvo culpa dolosa o negligencia grave, ni el tercero neutral ni el proveedor de servicios ODR serán responsables ante las partes de cualquier acto u omisión en relación con un procedimiento ODR realizado de conformidad con el Reglamento.]”

Observaciones

62. El proyecto de artículo 12 aborda la cuestión de la exclusión de responsabilidad de toda persona que intervenga en el procedimiento ODR. Refleja lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, con los ajustes necesarios.

63. Proyecto de artículo 13 (Costas)

“[El tercero neutral no emitirá [decisión alguna] [laudo alguno] acerca de las costas y cada parte habrá de sufragar sus propios gastos.]”

Observaciones

64. El término “costas” se refiere a una orden emitida por un tercero neutral a efectos de que una parte (en general, la parte perdedora) pague dinero a otra (en general, la parte ganadora) para compensar los gastos de la parte ganadora ocasionados por el caso.

65. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si, en caso de que prospere la reclamación del demandante en un procedimiento ODR en que intervenga el tercero neutral, deba ser el demandado quien haya de sufragar los honorarios de presentación de la demanda.

**C. Informe del Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias
en Línea sobre la labor de su 27º período de sesiones
(Nueva York, 20 a 24 de mayo de 2013)**

(A/CN.9/769)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción.	1-4
II. Organización del período de sesiones	5-11
III. Deliberaciones y decisiones.	12-13
IV. Solución en línea de controversias surgidas en operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento.	14-131
A. Propuestas para resolver cuestiones sustantivas pendientes en relación con el proyecto de reglamento para la solución en línea de las controversias surgidas en operaciones transfronterizas de comercio electrónico	14-44
B. Examen de las cuestiones sustantivas pendientes en relación con el proyecto de reglamento para la solución en línea de las controversias surgidas en operaciones transfronterizas de comercio electrónico	45-131
1. Proyecto de artículo 8 (Arreglo facilitado)	45-56
2. Proyecto de artículo 8 <i>bis</i> (Decisión del tercero neutral)	57-71
3. Proyecto de artículo 9 (Arbitraje)	72-105
4. Proyecto de artículo 6 (Nombramiento de un tercero neutral)	106-131
V. Otros asuntos	132

I. Introducción

1. En su 43º período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010), la Comisión convino en que se estableciera un Grupo de Trabajo con la misión de ocuparse de la solución en línea de las controversias surgidas en operaciones transfronterizas de comercio electrónico.

2. En su 44º período de sesiones (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011), la Comisión reafirmó el mandato del Grupo de Trabajo III sobre solución en línea de controversias surgidas a raíz de operaciones transfronterizas de comercio electrónico, incluidas las operaciones tanto entre empresas como entre empresas y consumidores¹. La Comisión decidió que, si bien el Grupo de Trabajo debía tener latitud para interpretar que su mandato abarcaba las operaciones entre consumidores y elaborar un posible reglamento que las regulase cuando fuera preciso, debería

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 218.*

tener especialmente en cuenta la necesidad de no dejar de lado la legislación de protección del consumidor².

3. En su 45º período de sesiones (Nueva York, 25 de junio a 6 de julio de 2012), la Comisión reafirmó el mandato del Grupo de Trabajo respecto de las operaciones electrónicas transfronterizas en gran volumen y de poca cuantía, y alentó al Grupo de Trabajo a que prosiguiera su labor de la manera más eficiente posible³. Se acordó también que el Grupo de Trabajo analizara la manera en que el proyecto de reglamento respondería a las necesidades de los países en desarrollo y otros países en situaciones posteriores a conflictos, en particular en lo que se refería a la necesidad de que el proceso constara de una etapa de arbitraje, y posteriormente informara a la Comisión en un futuro período de sesiones acerca de los resultados de dicho análisis, y que el Grupo de Trabajo siguiera examinando, en el marco de sus deliberaciones, los efectos del procedimiento de solución de controversias en línea en la protección del consumidor en países en desarrollo y desarrollados y en situaciones posteriores a conflictos.⁴

4. La recopilación más reciente de referencias relativas a la evolución del examen por la Comisión de la labor del Grupo de Trabajo se encuentra en el documento A/CN.9/WG.III/WP.118, párrafos 5 a 14.

II. Organización del período de sesiones

5. El Grupo de Trabajo III (Solución de Controversias en Línea), integrado por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 27º período de sesiones en Nueva York, del 20 al 24 de mayo de 2013. Asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Argelia, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Croacia, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Grecia, Honduras, India, Israel, Italia, Japón, Malta, México, Nigeria, República Checa, República de Corea, Singapur, Tailandia, Turquía, Ucrania, Venezuela (República Bolivariana de).

6. Asistieron también al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Belarús, Hungría, Indonesia, Irlanda, Omán, Países Bajos, Panamá, Qatar, República Democrática del Congo, Somalia, Túnez.

7. Asistieron además al período de sesiones observadores de la Unión Europea.

8. Asistieron asimismo al período de sesiones observadores de las siguientes organizaciones no gubernamentales internacionales: American Bar Association (ABA), Instituto Nacional Americano de Normalización (ANSI), Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG), Center for International Legal Education (CILE), Centre de Recherche en Droit Public (CRPD), Asociación Europea de Estudiantes de Derecho (ELSA), Foro de Conciliación y Arbitraje Internacionales C. I. C. (FICACIC), Instituto de Derecho Mercantil (Facultad de Derecho Dickinson de la Universidad del Estado de Pensilvania), Institute of International Commercial Law (IICL), Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (ILCE), Internet Bar

² *Ibid.*, párr.218.

³ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 79.

⁴ *Ibid.*, párr. 79.

Organization (IBO), Organización Marítima para África Occidental y Central (OMAO), Moot Alumni Association (MAA), New York State Bar Association (NYSBA), Regional Centre for International Commercial Arbitration - Lagos (RCICA), National Center for Technology and Dispute Resolution (NCTDR), y Unión Internacional de Abogados (UIA).

9. El Grupo de Trabajo eligió la siguiente Mesa:

Presidente: Sr. Soo-geun OH (República de Corea)

Relatora: Sra. Rosario Elena A. LABORTE-CUEVAS (Filipinas)

10. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí los siguientes documentos:

a) Programa provisional anotado (A/CN.9/WG.III/WP.118);

b) Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento (A/CN.9/WG.III/WP.119 y Add.1);

c) Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: plazos (A/CN.9/WG.III/WP.120);

d) Nota de la Secretaría relativa a la solución en línea de controversias surgidas a raíz de operaciones transfronterizas de comercio electrónico: otras cuestiones que deberán examinarse para elaborar un marco global que rija la solución de controversias en línea (ODR) (A/CN.9/WG.III/WP.113);

e) Propuesta del Gobierno del Canadá sobre los principios aplicables a los proveedores de servicios de solución de controversias en línea y a los terceros neutrales (A/CN.9/WG.III/WP.114); y

f) Nota presentada por el Center for International Legal Education (CILE) relativa al análisis de los principios sustantivos de la demanda y la reparación en la solución de controversias en línea y propuesta para incorporarlos al artículo 4 del proyecto de reglamento (A/CN.9/WG.III/WP.115).

11. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:

1. Apertura del período de sesiones.
2. Elección de la Mesa.
3. Aprobación del programa.
4. Examen de la solución en línea de controversias surgidas en el marco de operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento.
5. Otros asuntos.
6. Aprobación del informe.

III. Deliberaciones y decisiones

12. El Grupo de Trabajo reanudó su labor sobre el tema 4 del programa basándose en las notas preparadas por la Secretaría (A/CN.9/WG.III/WP.119 y su adición, y A/CN.9/WG.III/WP.120). Las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo respecto de este tema se recogen en el capítulo IV. Las deliberaciones del Grupo de Trabajo en relación con otros asuntos se recogen en el capítulo V.

13. Al clausurar sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara i) un proyecto de reglamento revisado para la solución en línea de las controversias surgidas en operaciones transfronterizas de comercio electrónico; y ii) un documento en que se expusieran los mecanismos privados de ejecución existentes.

IV. Solución en línea de las controversias surgidas en operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento

A. Propuestas para resolver cuestiones sustantivas pendientes en relación con el proyecto de reglamento para la solución en línea de las controversias surgidas en operaciones transfronterizas de comercio electrónico

14. Se recordó que al comienzo de su 26º período de sesiones, el Grupo de Trabajo había iniciado amplias consultas oficiosas para intentar llegar a un acuerdo respecto de algunas cuestiones fundamentales, es decir, considerar de qué manera podía el proyecto de reglamento para la solución en línea de las controversias surgidas en operaciones transfronterizas de comercio electrónico (“el Reglamento”) dar cabida tanto a una modalidad de solución de controversias en línea (“ODR”) que incluyera una fase de arbitraje como a otra que no la incluyera⁵.

15. Se recordó además que en esas consultas oficiosas se había formulado una propuesta, incluida como anexo del documento A/CN.9/762, en el sentido de elaborar un sistema de dos modalidades: una que terminaría en arbitraje, y otra que no.

16. En el 27º período de sesiones, varias delegaciones reiteraron que el Grupo de Trabajo debía formular un sistema global para la solución de controversias en línea en que tuvieran cabida tanto los ordenamientos jurídicos en que se establecía que los acuerdos de arbitraje previos a la controversia eran vinculantes para los consumidores como los que no.

Propuesta relativa a las controversias entre empresas solamente

17. Algunas delegaciones afirmaron que una posibilidad sería examinar en primer lugar un conjunto de reglas aplicables únicamente a las controversias entre empresas, y posteriormente pasar a deliberar sobre los problemas que planteaban las controversias surgidas entre empresas y consumidores. Se recordó que el mandato del Grupo de Trabajo abarcaba tanto las controversias entre empresas como las

⁵ Véase A/CN.9/762, párrs. 13 y 18.

controversias entre empresas y consumidores surgidas en operaciones en gran volumen y de poca cuantía, pero que la Comisión había encomendado al Grupo de Trabajo que considerase otros enfoques además del enfoque de un reglamento único.

18. Se afirmó que una propuesta que incluyera únicamente las controversias entre empresas tenía la ventaja de permitir al Grupo de Trabajo evitar las complejas cuestiones relativas a la protección del consumidor que, según se había dicho, habían dividido al Grupo, y de facilitar un examen más rápido del Reglamento.

19. En cuanto a la sugerencia de que examinar una propuesta que abarcara únicamente las controversias entre empresas ayudaría al Grupo de Trabajo a alcanzar un consenso, se dijo que, si bien ello podría ser una manera viable de avanzar en un principio, el Grupo de Trabajo no debía perder de vista su mandato relativo a las controversias surgidas en operaciones en gran volumen y de poca cuantía.

20. Se añadió que el Grupo de Trabajo debía tener presente que la mayoría de las controversias surgidas en operaciones en gran volumen y de poca cuantía serían entre consumidores y empresas, y que si el Reglamento se limitaba en esa etapa a las operaciones entre empresas, quedarían excluidas de él la mayoría de las operaciones que procuraba abarcar. Además, se señaló que la labor del Grupo de Trabajo hasta la fecha, así como los conocimientos acumulados sobre asuntos relativos a la protección del consumidor, se podrían perder si se excluían de las deliberaciones las operaciones entre empresas y consumidores.

Propuesta de aplicación del sistema de dos modalidades

21. Otras delegaciones propusieron un sistema de dos modalidades en que los comerciantes, en el momento de la operación, generarían dos cláusulas diferentes de solución de controversias en línea, en función de la jurisdicción en que se encontrara el comprador y su condición de comprador (empresa o consumidor). En virtud de esa propuesta, en el momento de realizar la operación se presentaría a los consumidores de las jurisdicciones en que los acuerdos de arbitraje previos a la controversia no fueran vinculantes para ellos (los llamados “Estados del Grupo I”), un acuerdo de solución de controversias en que se establecería que, en caso de controversia, se optaría por una modalidad ODR cuyo resultado no sería vinculante. Los consumidores de aquellas jurisdicciones en que los acuerdos de arbitraje previos a la controversia fueran vinculantes para ellos, así como los compradores que fueran empresas, recibirían un acuerdo de solución de controversias en que se establecería que, en caso de controversia, se optaría por una modalidad ODR que culminaría en una etapa de arbitraje, en caso de que el comerciante proyectara ofrecer la modalidad II del Reglamento.

22. Se sostuvo que en ese proceso el vendedor debería obtener la siguiente información: a) la dirección de envío o de facturación del comprador, para saber en qué jurisdicción se encontraba, y b) si la compra se realizaba con fines privados o profesionales, para saber si el comprador era un consumidor. Con esos datos, el sitio web del vendedor dirigiría al comprador automáticamente a la modalidad ODR adecuada.

23. Esa propuesta requeriría también que se añadiera un anexo al Reglamento en el que se especificara qué Estados pertenecían al “Grupo I” y cuáles no, a fin de proporcionar al vendedor información que le permitiera dirigir correctamente a los

consumidores a la modalidad adecuada en función de su jurisdicción. Se señaló que para que ese sistema funcionara se debería incluir en el Reglamento una definición de “consumidor”. Se sugirió que los consumidores de los Estados del “Grupo I” podrían convenir en someterse a arbitraje una vez surgida la controversia. Se dijo que esa propuesta era sencilla de aplicar desde el punto de vista técnico y permitía la interoperabilidad entre los distintos sistemas regionales.

24. En respuesta a lo anterior, se afirmó, en primer lugar, que una propuesta de esa índole obligaría al Grupo de Trabajo a volver a examinar una de las áreas fundamentales en las que había logrado consenso, a saber, el acuerdo de que no convenía definir el término “consumidor” en un texto internacional; y, en segundo lugar, que no correspondía al Grupo de Trabajo decidir la cuestión, expuesta en el párrafo anterior, de elaborar un anexo cuyo objeto fuese decidir por los Estados qué normas se aplicarían a los consumidores de esos Estados, y tampoco correspondía a los Estados proporcionar ese tipo de información ni actualizarla. Se señaló que, en caso de que algún Estado no proporcionara esa información, no se lo podría incluir en el anexo, y ello crearía graves problemas para aplicar el Reglamento.

25. Además se dijo que, si bien el Grupo de Trabajo podía elaborar una definición de “consumidor”, quedaría sin resolver la cuestión de la aplicación: cuándo aplicarla, a quién aplicarla y quién debía aplicarla. En cuanto a clasificar a los Estados en un anexo según sus leyes de protección del consumidor, se sostuvo que ello sería problemático dada la amplia variedad y la falta de uniformidad de las disposiciones, incluso en los Estados del “Grupo I”, relativas a los acuerdos de arbitraje previos a la controversia. Por todo ello, se juzgó conveniente acordar primero unas normas básicas en el contexto de las operaciones entre empresas y tratar las complejas cuestiones relativas a los consumidores en el futuro.

26. Por otra parte, se afirmó que para las jurisdicciones de *common law*, en las que la jurisprudencia y las normas de orden público podían evolucionar rápidamente, un anexo de esa índole sería poco útil y podría inducir a errores.

27. Otras delegaciones sugirieron también que la aplicación del sistema de dos modalidades no debía determinarse en función de la jurisdicción y la condición de los compradores (es decir, empresa o consumidor) en el momento de la operación. De lo contrario, en la práctica, el desarrollo de las operaciones de comercio electrónico se vería entorpecido.

28. En respuesta a ese argumento, las delegaciones que habían apoyado la propuesta contenida en los párrafos 21 a 23 *supra* sostuvieron que la definición de consumidor aparecía en otros instrumentos internacionales, como el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro, y que el Grupo de Trabajo podría tomar conocimiento de esas definiciones, teniendo en cuenta que no tenían por qué ser congruentes con las definiciones de consumidor de todos los Estados. También se afirmó que los países podrían optar por tomar ellos mismos la iniciativa de incluirse en la lista de países del “Grupo I”.

29. También se opinó que la propuesta sería incompatible con la estructura y la interpretación correcta de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, con lo cual se socavaría la práctica existente del arbitraje internacional.

Decisión

30. Después de un debate, se decidió que no predominaba la opinión de descartar el sistema de dos modalidades en favor de un conjunto de reglas aplicables únicamente a las controversias entre empresas a modo de etapa preliminar.

Propuesta de aplicación del sistema de dos modalidades

31. Se presentó una propuesta para que se examinara con mayor detenimiento el texto específico que habría de incluirse en la modalidad I, proyecto de artículo 1, y en la modalidad I, proyecto de artículo 2, para llevar a la práctica la propuesta descrita en los párrafos 21 a 23 *supra*. Se dijo que ese texto tenía por objeto facilitar las deliberaciones a fin de asegurar que los consumidores de determinadas jurisdicciones no estuvieran sujetos a una vía arbitral del procedimiento, sino únicamente a la hipotética “modalidad II”, que daría lugar a una etapa no arbitral del procedimiento.

32. Según esa propuesta se insertaría:

a) En el artículo 1 de la modalidad I del Reglamento, un párrafo 1 a) cuyo texto sería el siguiente: “1 a). *El presente Reglamento no se aplicará cuando una de las partes en la operación sea un consumidor de un Estado enumerado en el anexo X, salvo si el Reglamento se acordó después de surgida la controversia.*”

b) En el artículo 2 de la modalidad I del Reglamento, un párrafo 5 a) cuyo texto sería el siguiente: “5 a. *Por “consumidor” se entenderá una persona física que actúe principalmente con fines personales, familiares o domésticos.*”

33. Se dijo que la razón de la propuesta era velar por que un comprador, cuando se tratase de un consumidor, fuera orientado hacia la modalidad correcta del Reglamento en el momento de la operación. Se dijo que eso se lograría mediante la determinación por una de las partes de, en primer lugar, si provenía o no de un Estado que no considerara vinculantes para los consumidores los acuerdos de arbitraje previos a la controversia y, en segundo lugar, si se trataba o no de un consumidor.

34. Otro aspecto de la propuesta consistiría en incluir un anexo que comprendiera una lista de jurisdicciones, que optarían por quedar incluidas en esa lista a fin de excluir la aplicación de la modalidad I del Reglamento a los consumidores de esas jurisdicciones (conforme al proyecto de artículo 1 a) de esa propuesta, que figura en el párrafo 32 *supra*).

35. Se opinó que ese enfoque sería fácil de aplicar dado que se basaba en que los compradores proporcionarían dos datos sencillos, a saber, la dirección a la cual debían remitirse los envíos o las facturas, y si eran o no consumidores, y que esos datos, junto con la remisión a la lista de países que figuraría en el anexo propuesto, permitirían que el sitio web de un vendedor ofreciera automáticamente la cláusula de solución de controversias apropiada para el futuro comprador.

36. Varias delegaciones indicaron que la propuesta era útil para avanzar, y expresaron la opinión de que si bien el enfoque propuesto no era perfecto, podría dirigir eficazmente a los compradores a la modalidad ODR apropiada en un importante porcentaje de casos en el momento de la operación. También se dijo que, si bien podía existir el riesgo de que algunos compradores se dirigieran a la modalidad

equivocada, la propuesta atendía a un riesgo considerado aún mayor, a saber, que los consumidores pudieran encontrarse en una modalidad de arbitraje que no tenían intenciones de adoptar y que era inadecuada en vista de las leyes de protección del consumidor de sus jurisdicciones.

37. En relación con las cuestiones que requerían un ulterior examen, se dijo que la autonomía de las partes podría verse comprometida con un enfoque de ese tipo, y en particular se cuestionó si la CNUDMI debía, como cuestión de principio, o podía legalmente, aprobar un Reglamento que declaraba por sí mismo no ser aplicable a ciertos Estados o a ciertas partes como tales, según parecía desprenderse del artículo 1 a).

38. También se dijo que la definición del término “consumidor” que figuraba en esa propuesta requería un mayor examen. Por un lado, se dijo que la definición propuesta captaba la esencia de la definición de consumidor en muchas jurisdicciones, y proporcionaba un filtro preciso para un gran porcentaje de consumidores. Por otro lado, algunas delegaciones expresaron preocupación por el hecho de que esa definición pudiera clasificar erróneamente a demasiados consumidores o ser incompatible con muchas definiciones nacionales.

39. También se expresaron preocupaciones en relación con el requisito inherente a esa propuesta de que los consumidores se autoidentificaran como tales en el momento de la operación. Se dijo que esa autoclasificación podría dar demasiado margen a los consumidores para, ya fuera intencional o involuntariamente, clasificar su condición incorrectamente. En respuesta a esa preocupación, se dijo que si bien esa clasificación errónea era posible e incluso probable, la autoclasificación no era difícil, y ya existía en relación con ciertas operaciones informáticas y no informáticas.

40. En relación con el anexo propuesto, se preguntó quién mantendría la lista de jurisdicciones, y qué consecuencias habría cuando una jurisdicción se añadiera a la lista después que un consumidor de esa jurisdicción hubiera concluido un acuerdo en que se especificaba la modalidad I.

41. También se dijo que esa propuesta, que requería el suministro de datos por parte de los consumidores, tales como la autoclasificación y las direcciones a las que se les debían enviar los productos o las facturas, sería muy difícil de poner en práctica, particularmente en los casos de comerciantes que realizaran grandes volúmenes de operaciones diarias por Internet y de los lugares en que las ofertas del día o ventas relámpago (*flash sales*) eran muy populares y necesariamente exigían muy poco tiempo del comprador.

42. Algunas delegaciones dijeron también que si bien la propuesta proporcionaba una solución de transacción positiva a primera vista, era necesario realizar más consultas y obtener más instrucciones. Una delegación también presentó una objeción pues la propuesta era contraria a sus principios de orden público.

43. Tras un debate sobre la propuesta, se convino en que esta había recibido suficiente apoyo como para basar en ella futuras deliberaciones y en que, si bien algunas delegaciones habían expresado reservas, la propuesta era de encomiarse dado que había procurado poner en práctica en términos concretos el sistema de dos modalidades. Se convino en que todos los componentes de la propuesta se

colocarían entre corchetes para su ulterior examen y que sería necesario abordar más adelante las inquietudes que había suscitado la propuesta.

44. El Grupo de Trabajo pasó a examinar el proyecto de reglamento que figuraba en el documento A/CN.9/WG.III/WP.119/Add.1, empezando por el proyecto de artículo 8 (Arreglo facilitado).

B. Examen de las cuestiones sustantivas pendientes en relación con el proyecto de reglamento para la solución en línea de las controversias surgidas en operaciones transfronterizas de comercio electrónico

1. Proyecto de artículo 8 (Arreglo facilitado)

45. El Grupo de Trabajo examinó el proyecto de artículo 8 que figuraba en el párrafo 37 del documento A/CN.9/WG.III/WP.119/Add.1.

Observaciones generales

46. Se propuso incluir en los párrafos pertinentes del proyecto de artículo 8 una notificación a las partes cuando el procedimiento ODR pasara de una etapa a la siguiente; se señaló que, en el proyecto de reglamento, las palabras “pasará automáticamente” (por ejemplo, a la siguiente etapa del procedimiento) no ofrecían suficiente preaviso a las partes.

47. Se convino en añadir una disposición al proyecto de artículo 3 en que se previera dicha notificación y se encomendó a la Secretaría que la redactara como correspondiera.

48. Se dijo a ese respecto que la palabra “automáticamente” debía volver a examinarse específicamente en relación con el párrafo 2 del artículo 8 pues se refería a la modalidad I, que trataba de la transición del procedimiento de una etapa de arreglo facilitado a una etapa de arbitraje. Se dijo a ese respecto que la palabra “automáticamente” debía volver a examinarse específicamente en relación con el párrafo 2 de la modalidad I, que trataba de la transición del procedimiento de una etapa de arreglo facilitado a una etapa de arbitraje. En respuesta a ello se propuso insertar la siguiente frase al final de párrafo 2 (Modalidad I): “, y el proveedor de servicios ODR notificará con prontitud a las partes que han pasado de la etapa consensual a la etapa de arbitraje vinculante del procedimiento”.

49. Se aclaró que la palabra “automáticamente” tenía por objeto evitar la necesidad de que el tercero neutral o las partes intervinieran para desencadenar la etapa siguiente del procedimiento. Varias delegaciones se mostraron partidarias de mantener la palabra “automáticamente” para conservar ese significado. La propuesta de sustituir la palabra “automáticamente” por la frase “sin intervención de las partes o el tercero neutral” no recibió apoyo y se dijo que complicaba innecesariamente la redacción. Otra delegación propuso que se suprimiera la palabra “automáticamente”, dado que no era necesaria para transmitir el significado de la oración, es decir, que no era preciso adoptar medida adicional alguna para pasar a la etapa de arbitraje del procedimiento.

50. Tras deliberar, se acordó suprimir la palabra “automáticamente” del artículo 8 2) (Modalidad II), e insertar la formulación propuesta en el párrafo 48 *supra*, con las

modificaciones que la Secretaría considerase necesario introducir en el párrafo para mantener la coherencia con otras disposiciones.

Párrafo 1

51. En relación con el párrafo 1, se debatieron dos cuestiones. En primer lugar, se preguntó si la etapa del arreglo facilitado terminaba en el momento del arreglo, o bien en el momento en que el acuerdo de arreglo se consignaba en la plataforma ODR. Se aclaró que la segunda opción, que figuraba en la formulación actual, reflejaba el entendimiento de que, en un entorno informático, el acuerdo debía consignarse; para que se considerara que el acuerdo se había celebrado durante el procedimiento, debía consignarse antes de que este terminara.

52. Se convino en eliminar los corchetes del párrafo 1 para reflejar ese acuerdo.

53. En segundo lugar, se formuló una propuesta en relación con la segunda oración del párrafo 1, a saber, que un acuerdo de arreglo concertado durante la etapa del arreglo facilitado, únicamente en un procedimiento de la modalidad I, se presentara a un tercero neutral, quien otorgaría a dicho acuerdo la condición de laudo arbitral. Varias delegaciones expresaron su desacuerdo con esa propuesta, alegando que un acuerdo de arreglo era un acuerdo contractual entre las partes y que no debía mezclarse con la etapa de arbitraje de un procedimiento. Se convino en presentar una formulación de esa propuesta para que el Grupo de Trabajo la examinase y que tras ello podría ser necesario cambiar la ubicación de la segunda oración del párrafo 1. Se convino en examinar esa oración con mayor detenimiento en una etapa posterior.

Párrafo 2, modalidades I y II

54. Se dijo que para mantener la coherencia con el párrafo 1 y evitar dar lugar a una situación en que durante un tiempo el comprador no tuviera conocimiento del nombramiento de un tercero neutral, el párrafo 2 debía hacer referencia a la notificación a las partes del nombramiento de un tercero neutral, y no al propio nombramiento del tercero neutral. Se aclaró que en el proyecto de artículo 6.1 se estipulaba que el nombramiento de un tercero neutral se notificaría “rápidamente” a las partes y que para evitar dudas podría incluirse una referencia que remitiera a ese artículo.

Párrafo 2, modalidad II

55. Las dos opciones que se presentan en el párrafo 37 del documento A/CN.9/WG.III/WP.119/Add.1 se examinaron en relación con la etapa final del procedimiento de la modalidad II. En la opción 1, el procedimiento de la modalidad II terminaría al expirar la etapa del arreglo facilitado si no se había llegado a un arreglo. En la opción 2, se dictaría una decisión no vinculante.

56. La opción 2 recibió apoyo y varias delegaciones señalaron que la solución contenida en esa opción se ajustaba a los sistemas nacionales y a la legislación en vigor, además de los sistemas ODR existentes. Se acordó proceder tomando como base la opción 2, reconociendo que las deliberaciones al respecto no podrían disociarse por completo de las deliberaciones sobre el proyecto de artículo 8 *bis*).

2. Proyecto de artículo 8 bis) (Decisión del tercero neutral)

Observaciones generales

57. Como cuestión general en relación con el contenido del proyecto de artículo 8 bis), se solicitó a la Secretaría que en un futuro período de sesiones presentase un documento en que se expusieran los mecanismos privados de ejecución existentes. Esa solicitud obtuvo apoyo.

58. Se debatió si el término adecuado para el resultado de las deliberaciones del tercero neutral en la etapa del procedimiento del proyecto de artículo 8 bis) debía ser “decisión” o “recomendación”. Tras un examen de la cuestión, el Grupo de Trabajo convino en sustituir la palabra “decisión” en todo el proyecto de artículo 8 bis) por la palabra “recomendación”, que, según se dijo, reflejaba mejor el carácter previsto de la determinación no vinculante que debía adoptarse.

Párrafo 1

59. El Grupo de Trabajo convino en que se mantuviera la redacción del párrafo 1.

Párrafo 2

60. Se dijo que el tercero neutral debía formular una recomendación basada no solo en la información presentada por las partes, como se exigía en el párrafo 2, sino también en función de lo estipulado en el contrato, habida cuenta de la base contractual de las operaciones y, en consecuencia, de las controversias.

61. La propuesta recibió apoyo y, por consiguiente, se convino en añadir las palabras “y en función de lo estipulado en el contrato” después de “presentada por las partes”.

62. En relación con los corchetes del párrafo 2, se formuló una pregunta sobre el significado de consignar una recomendación en la plataforma ODR y, concretamente, si la información consignada estaría únicamente a disposición de las partes y el tercero neutral o si sería de acceso público. Se aclaró que el proyecto de artículo 8 bis) no contenía ninguna disposición relativa a la publicación de las recomendaciones que formulase un tercero neutral en relación con ese artículo. Varias delegaciones expresaron su conformidad con ese criterio y adujeron que no era viable publicar recomendaciones en el caso de controversias surgidas en operaciones en gran volumen y de poca cuantía. Tras un debate, se acordó eliminar los corchetes y mantener su contenido.

Párrafo 3

63. Se propuso suprimir el párrafo 3, alegando que en la etapa de recomendación de un procedimiento podía formularse una recomendación basada en los documentos proporcionados de conformidad con el artículo 4, y que las disposiciones complementarias relativas a la carga de la prueba eran innecesarias.

64. En respuesta a lo anterior se dijo que el párrafo 3 constituía un fundamento jurídico útil para formular una recomendación y que debía mantenerse. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en mantener la redacción del párrafo 3.

Párrafos 2 y 3

65. Se convino en invertir el orden de los párrafos 2 y 3 a fin de que se correspondiera mejor con la cronología natural del procedimiento.

Párrafo 4

66. Una delegación propuso una nueva redacción del párrafo 4: “La decisión [será ejecutable/se aplicará] mediante un mecanismo privado de conformidad con el mecanismo transfronterizo de ejecución mencionado en el párrafo 2 d) de los artículos introductorios del Reglamento”. Se dijo que ese enfoque permitiría mayor flexibilidad y abarcaría una mayor variedad de procedimientos de ejecución, incluidos mecanismos de ejecución que solo se establecerían mientras se concluía el proyecto de reglamento o tras su conclusión. Esta propuesta no recibió apoyo.

67. El Grupo de Trabajo examinó la primera oración del párrafo 4, que decía: “La decisión no será vinculante para las partes”. Se propuso que la intención de esa oración fuera que ninguna decisión dictada de conformidad con el proyecto de artículo 8 *bis*) tuviera fuerza de cosa juzgada, y que la disposición lo reflejara explícitamente.

68. En respuesta a lo anterior se dijo que la expresión “cosa juzgada” era confusa. Se adujo a modo de ejemplo que las consideraciones de “cosa juzgada” con respecto a los acuerdos de arreglo en el derecho continental diferían de los ordenamientos de *common law*. También se dijo que la utilización del término “cosa juzgada” podía impedir el acceso a muchos de los mecanismos de ejecución existentes. Por consiguiente, se convino en evitar el término “cosa juzgada”.

69. Por otra parte, se propuso modificar la redacción del párrafo 4 a fin de que afirmara que la formulación de una recomendación no sería óbice para que una parte presentara su caso ante un tribunal. Se dijo que esa propuesta no era lo suficientemente precisa y no recibió apoyo.

70. Se propuso que una recomendación fuese vinculante cuando las partes así lo acordaran, y que así quedara reflejado en la redacción del párrafo 4. La propuesta recibió apoyo y se hizo referencia a disposiciones similares de leyes nacionales. Se dijo que un acuerdo entre las partes daría a la recomendación un carácter contractualmente vinculante.

71. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en que el párrafo 4 reflejara la propuesta mencionada en el párrafo anterior, a saber, que la recomendación fuese vinculante cuando las partes así lo acordaran. El Grupo de Trabajo también consideró si las partes debían expresar su consentimiento con respecto al carácter vinculante de la recomendación después que esta se hubiera formulado, o si podían hacerlo en cualquier momento del procedimiento. Tras deliberar, se acordó por consenso que las partes podían expresar su consentimiento en cualquier momento. Teniendo en cuenta esas deliberaciones, se convino en modificar la primera oración del párrafo 4 de modo que dijera lo siguiente: “La decisión no será vinculante para las partes a menos que estas acuerden lo contrario”. Se convino en no modificar el resto del párrafo 4.

3. Proyecto de artículo 9 (Arbitraje)

72. El Grupo de Trabajo examinó el proyecto de artículo 9 que figuraba en el párrafo 54 del documento A/CN.9/WG.III/WP.119/Add.1.

Observaciones generales

73. El Grupo de Trabajo consideró si un tercero neutral podía continuar en funciones durante la etapa de arbitraje del procedimiento, o si debería nombrarse a un nuevo tercero neutral en el momento en que se iniciara el arbitraje.

74. Se expresaron diversas opiniones en relación con la cuestión de si el mismo tercero neutral podía actuar en la etapa de arreglo facilitado y en la etapa de arbitraje de un procedimiento. En general se estuvo de acuerdo en que el Reglamento debería constituir un medio rápido, eficiente y de bajo costo para solucionar controversias en relación con operaciones en gran volumen y de poca cuantía.

75. A tenor de lo que antecede, se formularon tres propuestas básicas.

76. La primera, formulada por las delegaciones que estaban a favor de nombrar a un tercero neutral distinto en una etapa de arbitraje, proponía que, si bien la situación por defecto debía consistir en el nombramiento de terceros neutrales diferentes para las dos etapas, las partes podían acordar expresamente mantener al mismo tercero neutral.

77. Se dijo que esa propuesta se fundamentaba en el hecho de que la legislación nacional de algunos Estados disponía que un mediador no debía actuar como árbitro en un mismo procedimiento. Se dijo además que el nombramiento de terceros neutrales diferentes era importante para preservar las diferentes funciones que desempeñaban el mediador y el tercero neutral, así como las diferentes consecuencias jurídicas de la mediación y el arbitraje, ya que, por ejemplo, podría no ser procedente que un tercero neutral que actuase en una etapa de arbitraje recibiera la información confidencial que se proporcionaba a un tercero neutral en una etapa de mediación. Se dijo que el hecho de mantener al mismo tercero neutral en ambos procesos podía dificultar la ejecución de un laudo.

78. La segunda propuesta consistía en mantener al mismo tercero neutral en todo el procedimiento, a menos que i) las partes acordaran otra cosa; o ii) ninguna de las partes opusiera una objeción. Varias delegaciones señalaron que su legislación nacional permitía la continuación del nombramiento y que, habida cuenta de que las operaciones que, según lo previsto, habría de abarcar el Reglamento eran en gran volumen y de poca cuantía, un procedimiento de esas características resultaría mucho más eficiente y menos costoso para las partes. En apoyo de esa propuesta se dijo también que el Reglamento tenía por objeto abordar un nuevo sistema de solución de controversias en línea que contuviera elementos de mediación y arbitraje, pero que el Reglamento no contemplaba una mediación cabal en que tuvieran lugar intercambios de información confidencial o ex parte que pudieran considerarse perjudiciales en algunas circunstancias o jurisdicciones. También se dijo que esa propuesta podía dar mayor eficiencia al procedimiento en cuanto a su duración y costo, y que el hecho de que las partes tuvieran derecho a oponerse unilateralmente a la continuación del nombramiento del mismo tercero neutral en una etapa de arbitraje ofrecía una salvaguardia suficiente.

79. En respuesta a lo anterior se dijo que, si bien el hecho de que el tercero neutral no se sustituyera en la etapa de arbitraje ayudaría a simplificar el procedimiento, había que salvar dos posibles obstáculos a esa propuesta. En primer lugar, se dijo que el intercambio de comunicaciones ex parte en una etapa de arreglo facilitado podía redundar en detrimento del resultado de un laudo dictado por el tercero neutral, y que para evitar ese problema el Reglamento debía prohibir expresamente las comunicaciones de esa índole en la etapa de arreglo facilitado. En segundo lugar, se dijo que un tercero neutral podía ejercer una influencia coercitiva indebida en una etapa de arreglo facilitado y que, a ese respecto, las partes deberían tener derecho a oponerse a la continuación del nombramiento del tercero neutral en la etapa de arbitraje.

80. Por último, se formuló una tercera propuesta de subsumir la etapa de arreglo facilitado en la etapa de arbitraje del procedimiento, como parte integrante de esa etapa. Se dijo que esa opción ofrecía la ventaja de que las partes tendrían conocimiento de que se encontraban en la fase de arbitraje y, por consiguiente, la cuestión de la imparcialidad del tercero neutral en dos etapas diferentes carecería de relevancia. Se propuso que, al comienzo de la etapa de arbitraje, el tercero neutral pudiera solicitar o exigir que las partes buscasen un arreglo facilitado; además, por analogía, se dijo que en el arbitraje comercial internacional se estaba empezando a afianzar como buena práctica que el árbitro alentase a las partes a llegar a un arreglo facilitado al comienzo del procedimiento. Las delegaciones que respaldaban esa propuesta adujeron que un proceso de dos etapas sería menos costoso que un proceso de tres etapas. También se aclaró que el Grupo de Trabajo ya había contemplado esa posibilidad en el pasado, y se hizo referencia al párrafo 128 del documento A/CN.9/744.

81. En respuesta a la tercera propuesta se dijo que el modo más indicado de abordar la solución de controversias en línea era mediante procesos no vinculantes y que, por consiguiente, la etapa del arreglo facilitado no debía subsumirse en una etapa de arbitraje; la necesidad de mantener esa etapa como parte de un proceso de tres etapas recibió amplio apoyo. También se mencionó que los requisitos de procedimiento y los costos de una etapa de arreglo facilitado diferían de los de una etapa de arbitraje.

82. El Grupo de Trabajo convino en seguir estudiando la cuestión en otro período de sesiones.

Párrafo 1

83. Se observó que en caso de que el Grupo de Trabajo determinara, en sus futuras deliberaciones con arreglo a los párrafos 73 a 82 *supra*, que debía nombrarse a un nuevo tercero neutral en la etapa del arbitraje, sería necesario modificar la redacción del párrafo 1 en consecuencia.

84. Se reiteró, tras las deliberaciones relativas al proyecto de artículo 8 2) (modalidad I), que debía notificarse claramente a las partes todo lo relacionado con la transición de la etapa del arreglo facilitado a la etapa de arbitraje del procedimiento.

85. Se propuso también que el plazo que el tercero neutral debía fijar para la presentación de la documentación definitiva estuviera vinculado más claramente al nombramiento del tercero neutral. A ese respecto, se propuso sustituir el párrafo 1

por el siguiente texto: “El tercero neutral fijará dentro de [x] días a partir de la recepción por las partes de la notificación mencionada en el artículo 8 2) un plazo máximo de 10 días de calendario para la presentación de la documentación definitiva”. Se recordó que el Grupo de Trabajo había modificado el proyecto de artículo 8 2) a fin de prever esa notificación a las partes (véanse los párrafos 48 y 50 *supra*).

86. Conforme a la propuesta que figura en el párrafo 84 *supra*, se convino en que la notificación a las partes en relación con la transición entre las etapas del procedimiento, tanto si se establecía en el proyecto de artículo 8 2) (modalidad I), como en el artículo 9 1), o en ambos, debía ser clara; y además, teniendo en cuenta la propuesta formulada en el párrafo 85 *supra*, debía fijarse un plazo bien definido para la presentación de la documentación tras la notificación. El Grupo de Trabajo encomendó en consecuencia a la Secretaría la tarea de formular las disposiciones pertinentes en el siguiente proyecto de reglamento.

87. También se solicitó a la Secretaría que velara por la coherencia, en todo el documento, de la redacción de las disposiciones relativas a la notificación a las partes. Se formuló una solicitud aparte a la Secretaría de que aclarara en la próxima versión del Reglamento, cuándo debían constar “por escrito” las notificaciones a las partes, o determinados documentos (como los acuerdos de arbitraje y los laudos).

Párrafo 2

88. Tras un debate, se acordó eliminar los corchetes y mantener su contenido. Se convino en que en todos sus restantes aspectos, el párrafo 2 se mantuviera en su forma actual.

Párrafo 3

89. Se convino en mantener el párrafo 3 en su forma actual.

Párrafos 2 y 3

90. El Grupo de Trabajo acordó invertir el orden de los párrafos 2 y 3 para respetar más la cronología natural del procedimiento y mantener la coherencia con el proyecto de artículo 8 *bis* (véase el párrafo 65 *supra*).

Párrafo 4

91. Se convino en mantener el párrafo 4 en su forma actual.

Párrafo 4 bis

92. Se acordó que, salvo toda modificación o reubicación de la definición de la palabra “escrito” requeridas si resultara necesario utilizar esa palabra en otras partes del Reglamento (véase el párrafo 87 *supra*), el párrafo 4 *bis* se mantendría en su forma actual.

Párrafo 5

93. Se convino en mantener el párrafo 5 en su forma actual.

Párrafo 6

94. Se planteó la cuestión de las consecuencias que traería aparejadas el hecho de que un tercero neutral no dictara el laudo en el plazo previsto en el párrafo 6. Se dijo que en algunos Estados un laudo podía ser inválido, o anularse, si el tercero neutral no cumplía el plazo fijado en el Reglamento o en la legislación nacional. Se observó que la rapidez era un aspecto clave de la ODR y que el Reglamento debía alentar la adopción de decisiones en tiempo oportuno.

95. Se formuló una propuesta de sustituir el texto del proyecto de párrafo 6 en su totalidad por el siguiente: “El laudo se dictará rápidamente, de preferencia dentro de los diez días de calendario [contados a partir de un momento determinado del procedimiento]”. Se expresó un fuerte apoyo a esta propuesta, que, según se dijo, reforzaba la necesidad de cumplir puntualmente los plazos del Reglamento y evitaba, al mismo tiempo, complejos argumentos jurídicos acerca de las consecuencias de una demora importante por parte del tercero neutral.

96. Tras un debate, se acordó adoptar la propuesta que figura en el párrafo anterior. También se acordó que en un documento en el que se establecieran directrices para los proveedores de servicios ODR, se podrían abordar cuestiones de puntualidad incluido, por ejemplo, el reemplazo del tercero neutral que no cumpliera oportunamente sus obligaciones.

Párrafo 6 bis

97. Se expresó apoyo al contenido del párrafo 6 *bis* sobre la base de que articulaba las deliberaciones del Grupo de Trabajo en su 26º período de sesiones, y reflejaba además la redacción existente del artículo 34 5) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

98. Se convino en eliminar los corchetes y mantener el contenido del párrafo 6 *bis* tal como estaba redactado. Se propuso además que la publicación de estadísticas y resúmenes de las decisiones en relación con el procedimiento ODR fuera una cuestión que se abordara en un documento en el que se establecieran directrices para los proveedores de servicios ODR.

Párrafo 7

99. Se convino en que se mantuviera el párrafo 7 tal como estaba redactado.

Párrafo 8

100. Se expresaron una serie de opiniones en relación con el párrafo 8, disposición nueva que se había insertado para tener en cuenta las normas sustantivas de fondo en el contexto del proyecto de Reglamento.

101. En apoyo del párrafo 8 se dijo que, por un lado, reflejaba un enfoque adoptado en otros textos de la CNUDMI, incluidos la Ley Modelo y el Reglamento de Arbitraje. Se dijo también que el principio de *ex aequo et bono* brindaba una base conveniente y de sentido común para solucionar controversias surgidas en operaciones en gran volumen y de poca cuantía, y que ese principio se utilizaba en algunos países en relación con esas controversias.

102. Por otro lado, se dijo que una disposición *ex aequo et bono* era ambigua y equivalía esencialmente a una falta de derecho sustantivo, que daba demasiada discrecionalidad al tercero neutral. A ese respecto, se formuló una propuesta para modificar el párrafo 8 de modo que previera la adopción de una decisión de acuerdo con las condiciones del contrato y además, *ex aequo et bono*. Se expresó cierto apoyo para esta propuesta. En respuesta, se adujo que exigir que un tercero neutral actuara *ex aequo et bono* y, al mismo tiempo, de conformidad con las condiciones del contrato, podía resultar confuso pues dichas condiciones podrían prescribir la aplicación del derecho interno.

103. Se expresó otra opinión en el sentido de que el recurso al derecho tradicional aplicable no sería apropiado en el contexto de la ODR, y que una solución mejor consistiría en hacer referencia en el párrafo 8 a un documento que aún no se había redactado, pero que se mencionaba en el proyecto de preámbulo del Reglamento, en el que se abordarían los principios jurídicos sustantivos aplicables a las controversias. También se expresó cierto apoyo a esta propuesta.

104. Se dijo asimismo que el de *ex aequo et bono* era un concepto jurídico que resultaría difícil de entender para los consumidores, y que la misma idea debería expresarse en un lenguaje sencillo.

105. Tras deliberar, se convino en que la expresión “*ex aequo et bono*” se colocaría entre corchetes y que la Secretaría propondría formulaciones alternativas en un futuro período de sesiones del Grupo de Trabajo.

4. Proyecto de artículo 6 (Nombramiento de un tercero neutral)

106. El Grupo de Trabajo examinó el proyecto de artículo 6 que figuraba en el párrafo 16 del documento A/CN.9/WG.III/WP.117/Add.1, en relación con el nombramiento del tercero neutral.

Observaciones generales

107. Se aclaró que el Grupo de Trabajo examinaría el proyecto de artículo 6 primero en relación con las normas de la modalidad I, lo cual permitiría que el Grupo de Trabajo reanudara más adelante el examen de un enfoque potencialmente simplificado o agilizado para el nombramiento del tercero neutral con arreglo al conjunto de normas correspondientes a la modalidad II.

Párrafo 1

108. Se propuso suprimir la frase entre corchetes “o que provenga de otras instituciones arbitrales”, a menos que hubiera un modo de asegurar que un proveedor de servicios ODR pudiera supervisar esa lista y que la ampliación de la lista a otras instituciones arbitrales pudiera conllevar el riesgo de que esa función de supervisión perdiera eficacia, o se anulara. Se afirmó que, si bien aún no se había redactado ningún documento de orientación para proveedores de servicios ODR y terceros neutrales, estaba previsto que el proveedor de servicios ODR presentara una lista de terceros neutrales a la que tuvieran acceso las partes. Se dijo además que un proveedor de servicios ODR podría ejercer cierta función de supervisión en relación con los terceros neutrales, e incluso reemplazarlos durante el procedimiento, de ser necesario, y que los proveedores de servicios ODR y los terceros neutrales

conocerían el arbitraje simplificado previsto en el Reglamento, que, según se señaló, difería del arbitraje tradicional.

109. A ese respecto, se propuso también que la identidad de los terceros neutrales se pusiera en conocimiento de las partes, de modo que pudieran oponer una objeción razonable a dicho nombramiento.

110. Tras deliberar, se convino en suprimir la frase “[o que provenga de otras instituciones arbitrales]”, y en comunicar a las partes la identidad del tercero neutral tras su nombramiento. Se solicitó a la Secretaría que en la próxima versión del Reglamento incluyera la formulación pertinente.

Párrafo 2

111. Se expresó apoyo por el párrafo 2, dado que reflejaba otras disposiciones contenidas en textos de la CNUDMI (por ejemplo, una declaración modelo incluida en un anexo del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010).

112. No obstante, se dijo que, si bien una disposición de esa índole era suficientemente importante para figurar en el Reglamento, también se podía considerar que imponía una obligación a un tercero neutral; se dijo que el Reglamento no podía tener esa finalidad, dada su condición de acuerdo contractual entre las partes en una controversia y que, en consecuencia, debía reformularse el párrafo 2. También se cuestionó si era adecuado trasladar al proveedor de servicios ODR la responsabilidad de garantizar que el tercero neutral tuviera capacidad suficiente para desempeñar su función y si el Reglamento podía obligar al proveedor de servicios ODR en ese sentido.

113. Se aclaró que un proveedor de servicios ODR, de manera similar a una institución arbitral que administrara un arbitraje siguiendo las disposiciones de los textos de la CNUDMI, no era una parte contractual en el Reglamento. Además, se dijo que la formulación del párrafo 2 seguía la línea de otros instrumentos similares y proporcionaba una orientación útil en relación con los deberes del tercero neutral, que eran suficientemente importantes como para figurar en el Reglamento.

114. Por consiguiente, se acordó suprimir los corchetes y mantener el texto del párrafo 2 de la manera en que estaba redactado.

Párrafo 3

115. Obtuvo un amplio apoyo la idea de mantener el principio incluido entre corchetes, es decir, que la obligación del tercero neutral de dar a conocer cualquier circunstancia que pudiera suscitar dudas fundadas acerca de su imparcialidad o de su independencia era una obligación permanente.

116. Se observó que si se suprimía la frase entre corchetes, la disposición tal vez no fuera suficientemente clara respecto de la necesidad de que el tercero neutral diera a conocer las circunstancias que existían en el momento de su nombramiento. Como posibles ejemplos para captar mejor ese principio se citaron el artículo 11 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 y el artículo 12 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.

117. Se convino en suprimir los corchetes del párrafo 3 a fin de mantener la obligación de dar a conocer en cualquier momento toda circunstancia que pudiera

susitar dudas fundadas acerca de la imparcialidad o independencia del tercero neutral, y se solicitó a la Secretaría que hiciera las modificaciones necesarias al párrafo para garantizar que las circunstancias preexistentes en el momento del nombramiento que debían ser objeto del requisito de divulgación en virtud del párrafo 3 también quedaran incluidas en la obligación expresada en ese párrafo.

Párrafo 4

118. Se convino en suprimir la frase “presentará su renuncia e informará en consecuencia a las partes y al proveedor de servicios ODR”, que figuraba entre corchetes. Se convino también en que, por ser el párrafo 4 redundante en vista de las modificaciones hechas en el párrafo 3, según lo expuesto más arriba en los párrafos 116 y 117, debía por tanto eliminarse.

119. Además, se acordó que la Secretaría redactara una nueva disposición en que se trataran en términos generales la renuncia y la sustitución de los terceros neutrales, incluidos los casos en que los terceros neutrales desearan renunciar por motivos de independencia e imparcialidad, que se examinaría en un período de sesiones futuro.

Párrafo 5

120. Se preguntó si convendría suprimir el texto que figuraba entre corchetes “sin indicar los motivos”. Se explicó que el texto obedecía al deseo de proporcionar un procedimiento rápido y simple para una impugnación o recusación sin causa de terceros neutrales, sin las demoras y complejidades que entrañaba el proporcionar una justificación en el momento del nombramiento. Tras un debate, se acordó conservar el texto y suprimir los corchetes.

121. Se aclaró que existían dos maneras, con arreglo al párrafo 5, de descalificar a un tercero neutral: en primer lugar, en el momento del nombramiento, cuando se había acordado que no era necesario dar razones y la descalificación sería automática; y, en segundo lugar, en cualquier momento durante el procedimiento, aduciendo que había surgido un hecho o asunto nuevo que llevaba a susitar dudas sobre la imparcialidad o independencia del tercero neutral.

122. Se convino también en que el texto “[incluidas la declaración o la comunicación del tercero neutral conforme a lo dispuesto en el párrafo 3) [o 4)]” era innecesario y podía suprimirse.

123. En todos los demás aspectos, se acordó mantener la redacción del párrafo 5 y suprimir todos los corchetes restantes, salvo los de los plazos, que se considerarían de manera conjunta con otros plazos del Reglamento en un futuro período de sesiones.

Párrafo 5 bis

124. Tras un debate, y después de recordar la aclaración hecha en cuanto al contenido del párrafo 5 y las dos formas de descalificar a un tercero neutral, se afirmó que la redacción del párrafo 5 *bis* podía simplificarse o dividirse en dos o tres párrafos separados para mayor claridad.

125. Se encomendó a la Secretaría que volviera a examinar el texto y modificara la redacción en consecuencia.

126. En todos los demás aspectos, se acordó mantener la redacción del párrafo 5 *bis* y suprimir todos los corchetes, salvo los relacionados con los plazos.

Párrafo 6

127. Se acordó mantener la redacción y suprimir los corchetes del párrafo 6.

Párrafo 7

128. Se manifestó amplio apoyo a la idea de mantener el contenido del párrafo 7 tal como estaba redactado. También obtuvo apoyo la propuesta de que se suprimiera el texto entre corchetes “[y a informar a las partes rápidamente de esa elección]” por redundante, en vista de la redacción actual del párrafo 1.

129. Tras un debate, se acordó suprimir todos los corchetes del párrafo 7, y también aceptar la propuesta de suprimir las palabras “y a informar a las partes rápidamente de esa elección”. Salvo esas modificaciones, el párrafo 7 se mantiene en su forma actual.

Párrafo 8

130. Se expresó apoyo al principio de que el Reglamento, tal como estaba redactado hasta la fecha, previera la actuación de solo un tercero neutral y, desde el punto de vista práctico, el nombramiento de solo un tercero neutral era más apropiado en el contexto de controversias surgidas en las operaciones en gran volumen y de poca cuantía que regía el Reglamento. Se reconoció también que, puesto que el Reglamento era un acuerdo contractual entre las partes, nada les impedía estipular otra cosa.

131. Tras un debate, se acordó suprimir el texto entre corchetes.

V. Otros asuntos

132. El Grupo de Trabajo observó que, a reserva de su confirmación por la Comisión, la celebración del 27º período de sesiones estaba prevista para los días 7 a 11 de octubre de 2013, en Viena.

D. Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 27º período de sesiones

(A/CN.9/WG.III/WP.119 y Add.1)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción.	1-4
II. Solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento.	5-69
A. Observaciones generales	5-22
B. Notas sobre el proyecto de reglamento	23-69
1. Artículos introductorios	23-52
2. Apertura del procedimiento	53-69

I. Introducción

1. En su 43º período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010), la Comisión convino en que se estableciera un Grupo de Trabajo que se ocupara de la solución en línea de controversias surgidas a raíz de operaciones transfronterizas de comercio electrónico, incluidas las operaciones entre empresas y las operaciones entre empresas y consumidores¹. En sus períodos de sesiones 44º (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011)² y 45º (Nueva York, 25 de junio a 6 de julio de 2012)³, la Comisión reafirmó el mandato del Grupo de Trabajo sobre la solución de controversias en línea surgidas a raíz de operaciones transfronterizas de comercio electrónico, incluidas las operaciones entre empresas y las operaciones entre empresas y consumidores.

2. En su 22º período de sesiones (Viena, 13 a 17 de diciembre de 2010)⁴, el Grupo de Trabajo inició su examen del tema de la solución de controversias en línea y pidió a la Secretaría que, a reserva de los fondos de que dispusiera, preparara un proyecto de reglamento genérico para la solución en línea de controversias surgidas a raíz de operaciones transfronterizas de comercio electrónico (el “Reglamento”) y tuviera en cuenta que los tipos de demandas de los que se ocuparía ese Reglamento serían las relacionadas con operaciones transfronterizas de poco valor y muy numerosas realizadas entre empresas y entre empresas y

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), párr. 257.*

² *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17).

³ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17).

⁴ El informe sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo en su 22º período de sesiones figura en el documento A/CN.9/716.

consumidores⁵. Desde su 23º período de sesiones (Nueva York, 23 a 27 de mayo de 2011)⁶ hasta su 26º período de sesiones (Viena, 5 a 9 de noviembre de 2012)⁷, el Grupo de Trabajo examinó consecutivamente el proyecto de reglamento genérico que figuraba en los documentos A/CN.9/WG.III/WP.107, A/CN.9/WG.III/WP.109, A/CN.9/WG.III/WP.112 y su adición y A/CN.9/WG.III/WP.117 y su adición.

3. En su 26º período de sesiones, el Grupo de Trabajo reconoció que podrían ser necesarias en el Reglamento dos modalidades para dar cabida a las jurisdicciones en las que se consideran vinculantes para los consumidores los acuerdos de arbitraje celebrados antes de la controversia (“acuerdos de arbitraje previos a la controversia”) y las jurisdicciones en las que no se consideran vinculantes para los consumidores (A/CN.9/762, párrs. 13 a 25 y anexo).

4. En la presente nota figura un proyecto anotado del Reglamento en el que se tienen en cuenta las deliberaciones mantenidas por el Grupo de Trabajo en sus períodos de sesiones anteriores, incluida su solicitud de que incluyeran “dos modalidades” de artículos, como se expone en el párrafo 3 *supra*.

II. Solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento

A. Observaciones generales

Naturaleza jurídica del Reglamento

5. El Grupo de Trabajo tal vez desee tener en cuenta cuando examine el Reglamento que, como se enuncia en el proyecto de artículo 1, es de naturaleza contractual y nada de lo dispuesto en él anula lo dispuesto en la legislación de obligado cumplimiento.

6. En el 26º período de sesiones del Grupo de Trabajo se manifestaron dos enfoques en relación con la aplicación del Reglamento: i) con arreglo al primer enfoque, los acuerdos de arbitraje previos a la controversia se deberían aplicar a todas las operaciones entre empresas y consumidores y operaciones entre empresas y ii) con arreglo al segundo enfoque, puesto que los acuerdos de arbitraje previos a la controversia no se consideran vinculantes para los consumidores en determinadas jurisdicciones, las controversias de los consumidores de esas jurisdicciones no se deberían solucionar mediante arbitraje (A/CN.9/762, párrs. 15, 17, 18, 20 a 22 y anexo).

7. En consecuencia, lo que el Grupo de Trabajo venía a proponer en el documento de debate que figura como anexo del documento A/CN.9/762 era que el Reglamento incluyese diferentes conjuntos de disposiciones dependiendo de si el

⁵ A/CN.9/716, párr. 115.

⁶ El informe sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo en su 23º período de sesiones figura en el documento A/CN.9/721.

⁷ El informe sobre la labor realizada por el Grupo de Trabajo en su 26º período de sesiones figura en el documento A/CN.9/762.

derecho interno del consumidor permite que un acuerdo de arbitraje anterior a la controversia sea vinculante para ese consumidor.

Dos modalidades de artículos en el Reglamento

8. Teniendo presente esa propuesta del Grupo de Trabajo, se examinaron las opciones siguientes para crear dos modalidades de artículos en el Reglamento conforme a ella:

- Exigir en el momento de la operación una de las siguientes cosas:

i) al vendedor que distinga si el comprador es una empresa o un consumidor, y la jurisdicción de este, en su caso, y adapte en consecuencia la cláusula correspondiente sobre solución de controversias;

ii) a los compradores que se clasifiquen a sí mismos (es decir, que se identifiquen como consumidores o empresas) e indiquen si están sometidos a la legislación de una determinada jurisdicción;

iii) a quienes se identifiquen como consumidores que escojan en el momento de la operación si preferirían un procedimiento de solución de controversias en línea (procedimiento ODR) que terminase en arbitraje o no;

- Exigir durante las actuaciones o en el momento de presentar una demanda:

iv) al tercero neutral que determine la jurisdicción del consumidor y si la parte era un consumidor o una empresa; o

v) al proveedor de servicios ODR que determine la jurisdicción del consumidor y si la parte era un consumidor o una empresa;

vi) a algunos o a todos los demandantes que hagan un “segundo clic” cuando interpongan una demanda, además de la acción de interponer la demanda (que es en sí misma probablemente un acuerdo de arbitraje posterior a la controversia, véase el documento A/CN.9/744, párr. 20), a fin de indicar el consentimiento del demandante, en esa etapa posterior a la controversia, para participar en un proceso que termine en un arbitraje vinculante (véase A/CN.9/744, párr. 33).

9. Las dificultades que se percibían en relación con los enfoques anteriores eran las siguientes. En relación con el apartado i), exigir a los vendedores que determinen si la otra parte es una empresa o un consumidor, la jurisdicción correspondiente y el derecho aplicable a esa otra parte y que adapten en consecuencia su cláusula sobre solución de controversias probablemente frustraría uno de los objetivos hipotéticos del Reglamento, a saber, evitar a los comerciantes la carga y el riesgo de esas averiguaciones para alentarlos a realizar ventas transfronterizas. El Grupo de Trabajo ya reconoció las dificultades inherentes para establecer una distinción entre consumidores y empresas en el contexto de las operaciones en línea (véanse por ejemplo A/65/17, párr. 265; A/CN.9/721, párr. 35). En relación con los apartados ii) y iii), la clasificación por los propios consumidores y la elección del resultado deseado probablemente no satisfarían a las delegaciones que deseaban la aplicación válida de los acuerdos de arbitraje previos a la controversia a todas las partes, cuando lo permita la ley (A/CN.9/762, párr. 18), ni necesariamente ofrecería una mayor protección a los consumidores. Además, el objetivo del Reglamento no es solo regular las operaciones entre empresas y consumidores, sino que, de acuerdo con el mandato de la Comisión, se aplicaría

igualmente a las operaciones entre empresas. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si conviene que los demandados que sean empresas tengan la posibilidad de autoexcluirse de una etapa de arbitraje al principio de las actuaciones.

10. En relación con el apartado iv), que un tercero neutral que se encargue de una controversia simple de poco valor entre partes de cualquier lugar del mundo tenga que ocuparse de determinaciones complejas sobre la residencia, los requisitos jurisdiccionales y la elección del derecho aplicable no es lo que se prevé para el Reglamento. Y esas determinaciones tampoco producirían un proceso eficiente de solución de controversias.

11. En relación con el apartado v), el Grupo de Trabajo tal vez desee recordar que los proveedores de servicios ODR serán entidades privadas, con toda probabilidad seleccionadas por empresas y prescritas en contratos de adhesión, para que proporcionen un servicio ODR. El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si esas entidades estarían dispuestas a dictaminar con precisión, por ejemplo, el lugar de residencia de los consumidores y a aplicar resultados distintos en función de esos dictámenes, o si serían capaces de hacerlo, e incluso en caso afirmativo, si los consumidores aceptarían ese tipo de determinación y dónde podrían recurrir en caso de no aceptarla.

12. Por último, en relación con el apartado vi) del párrafo 8 *supra*, o cualquier variación de él, la validez de la cláusula inicial sobre solución de controversias podría verse en peligro si tuviese que ser reemplazada por un segundo “reconocimiento” o acuerdo. En cualquier caso, ese segundo clic de los consumidores posterior a la controversia no podría resolver ningún problema relacionado con los demandados que sean consumidores. Y un acuerdo de arbitraje aceptado por ambas partes con posterioridad a la controversia tampoco parecería práctico ni en las operaciones entre empresas ni en la inmensa mayoría de las operaciones entre empresas y consumidores, en las que la parte demandada será probablemente una empresa, con lo que se limitaría mucho la capacidad de los demandantes de obtener reparación en virtud del Reglamento cuando una empresa demandada rehusase el arbitraje después de la controversia.

13. Con respecto a la mayoría de las posibles determinaciones indicadas *supra*, pueden surgir controversias en relación con las clasificaciones, al margen de la controversia sobre la cuestión de fondo que se pretende resolver mediante el procedimiento ODR.

14. Además, que un reglamento sea un sistema autosuficiente y global tiene diversas ventajas. En primer lugar, el objetivo de un reglamento es ofrecer un proceso jurídico claro y, especialmente en un contexto de controversias simples de poco valor en las que a menudo intervienen consumidores, el reglamento debería ser claro y simple. En segundo lugar, un reglamento es de naturaleza contractual y por ello, está sujeto a la legislación de obligado cumplimiento. De ese modo, un único instrumento coherente ya está sujeto a la posibilidad de ser derogado en determinados aspectos por el derecho interno; introducir una complejidad adicional en el Reglamento podría hacerlo difícil de utilizar. Por último, añadir un elemento de discreción o clasificación en un reglamento y conferir así determinados derechos adicionales a las partes en algunas jurisdicciones o imponer obligaciones complejas a terceros como los proveedores de servicios ODR o los terceros neutrales, puede ser simplemente inviable en la práctica.

Proyecto de nueva estructura del Reglamento

15. Por consiguiente, el presente proyecto de reglamento se ha redactado como dos conjuntos separados de artículos: uno que termina en la etapa del arbitraje vinculante (provisionalmente denominado “Modalidad I”) y otro (provisionalmente denominado “Modalidad II”) con dos posibles resultados finales para que los examine el Grupo de Trabajo: o bien un resultado que termine i) al concluir la etapa del arreglo facilitado, aunque no se haya alcanzado ninguno; o ii) si no se ha alcanzado un arreglo, con una decisión no vinculante de un tercero neutral, ejecutable por conducto de mecanismos privados como los sellos de confianza. Ese último enfoque recibió apoyo como tercera alternativa al sistema de “dos modalidades” en el 26º período de sesiones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/762, párrs. 19 a 21).

16. Por ello, en las cláusulas sobre solución de controversias se debería especificar si las controversias dimanantes de esa operación se solucionarían con arreglo a la “Modalidad I” o la “Modalidad II” del “Reglamento ODR de la CNUDMI”. Por ello, en la práctica el vendedor no determinaría la jurisdicción ni la condición (consumidor o empresa) de la otra parte del contrato; en lugar de ello, se aplicaría la modalidad especificada en la cláusula sobre solución de controversias con independencia de la naturaleza del comprador. Cada modalidad comprendería un conjunto autónomo de artículos.

17. Con este enfoque se trata de dar cabida a las dos posturas expresadas por el Grupo de Trabajo en su 26º período de sesiones al tiempo que se tienen en cuenta las dificultades jurídicas y prácticas de determinar, antes o durante la controversia, el tipo de comprador y su jurisdicción o jurisdicciones. Si en una cláusula sobre solución de controversias se especifica que las controversias dimanantes de la operación se guiarán por la Modalidad I del Reglamento (y terminarán en arbitraje), el laudo definitivo sería vinculante para todas las partes donde así lo permita el derecho interno. Los consumidores de jurisdicciones en las que los acuerdos de arbitraje previos a la controversia no se consideran vinculantes para ellos participarían en el mismo proceso ODR pero, conforme a su legislación nacional, el laudo no sería vinculante para ellos (a falta de un acuerdo de arbitraje posterior a la controversia). Si en una cláusula sobre solución de controversias se especifica que las controversias dimanantes de la operación se guiarán por la Modalidad II del Reglamento, el procedimiento no terminará en arbitraje para ninguna de las partes.

18. Lo ideal sería que en la página web de la empresa vendedora o incluso en un enlace interno dentro de la cláusula sobre solución de controversias se expusiesen los efectos de sus procedimientos de solución de controversias; entre ellos, los efectos que tiene para los consumidores de determinadas jurisdicciones el carácter no vinculante de una cláusula de solución previa a la controversia, por ejemplo. Sin embargo, dado que imponer obligaciones a empresas no está al alcance del Reglamento, el Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si en las directrices para los proveedores de servicios ODR se debería exigir que se indiquen clara y simplemente los efectos de la Modalidad I o la Modalidad II del Reglamento (la que sea aplicable) para cada parte cuando se interpone una demanda.

19. El contenido del proyecto de reglamento con dos modalidades que se propone figura en los párrafos 23 a 69 *infra*. Aunque por economía de redacción en la presente nota no se repiten las disposiciones que serían comunes para las dos

Modalidades, el Reglamento definitivo necesariamente incluiría dos conjuntos de artículos separados y autónomos (la Modalidad I y la Modalidad II), sin elementos compartidos ni remisiones a la otra Modalidad, de manera que los usuarios acogidos a cada Modalidad se podrían remitir independientemente a cada una de ellas.

20. El Grupo de Trabajo tal vez desee tener en cuenta que el proyecto de preámbulo y el proyecto de artículos 1 a 7 y 11 a 15 serían idénticos en las modalidades I y II. El párrafo 2) del proyecto de artículo 8 se adaptaría a cada modalidad. La modalidad II incluiría además el proyecto de artículo 8 *bis*); la modalidad I, los proyectos de artículo 9, 9 *bis*), 9 *ter*) y 10.

Cuestiones de redacción

21. El Grupo de Trabajo tal vez desee tener en cuenta que, en aras de la coherencia, se han introducido los cambios siguientes en todo el Reglamento. En primer lugar, y en consonancia con otros instrumentos de la CNUDMI, se ha utilizado en todo el Reglamento la palabra “rápidamente”, en lugar de la expresión “sin dilación”, allí donde se proponían como variantes. En segundo lugar, la expresión “presentado a la plataforma ODR” ha sido sustituida por “comunicado a un proveedor de servicios ODR”, con el objetivo de lograr una mayor coherencia con las definiciones que figuran en el proyecto de artículo 2 y mejorar también la coherencia más generalmente en todo el Reglamento.

Proveedor de servicios ODR y plataforma ODR

22. A título de observación general, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si la relación entre la plataforma ODR y el proveedor de servicios ODR está suficientemente clara en el Reglamento y si la delimitación de las funciones de esas entidades está claramente formulada dentro del proceso ODR. Aunque el documento suplementario en el que se establecerán las directrices para los proveedores de servicios ODR puede contribuir a vertebrar más esa cuestión, el Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si se deberían expresar más claramente en el Reglamento las funciones respectivas. Las definiciones de plataforma ODR y proveedor de servicios ODR se han modificado ligeramente para intentar aclarar la relación entre esas entidades (párrafos 2) y 3) del proyecto de artículo 2), al igual que el primer párrafo del proyecto de artículo 3).

B. Notas sobre el proyecto de reglamento

1. Artículos introductorios

23. Proyecto de preámbulo

“1. El reglamento de la CNUDMI para la solución de controversias en línea (“el Reglamento”) tiene la finalidad de ser utilizado en el contexto de operaciones transfronterizas de poco valor y de gran volumen realizadas por medios electrónicos de comunicación.

2. Se ha previsto que el presente Reglamento sea aplicado en un marco jurídico para la solución de controversias en línea que conste de los siguientes documentos que [se adjuntan al presente Reglamento como anexos y que] formarán parte del mismo:

[a) Directrices y requisitos mínimos para los proveedores de servicios de solución de controversias en línea;]

[b) Directrices y requisitos mínimos para los terceros neutrales;]

[c) Principios jurídicos sustantivos para resolver controversias;]

[d) Mecanismo transfronterizo de ejecución;]

[...];

[3. [Toda regla separada y suplementaria] [Todo documento separado y suplementario] deberá ser conforme al Reglamento.]”

Observaciones

Párrafo 2)

24. En su 24º período de sesiones, el Grupo de Trabajo observó que la lista de documentos enunciada en el párrafo 2) no era exhaustiva (A/CN.9/739, párr. 21). El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar cuáles de esos documentos y qué documentos adicionales debería preparar en cumplimiento de su mandato. El Grupo de Trabajo tal vez desee tener en cuenta que en los documentos A/CN.9/WG.III/WP.113, A/CN.9/WG.III/WP.114 y A/CN.9/WG.III/WP.115 se tratan cuestiones relacionadas con los documentos mencionados en el párrafo 2).

Párrafo 3)

25. Los proveedores de servicios ODR pueden decidir adoptar reglas suplementarias para resolver las cuestiones que no estén contempladas en el Reglamento y que puedan exigir un tratamiento distinto por parte de cada uno de ellos, como, por ejemplo, los costos, la definición de los días de calendario⁸ o las respuestas a la impugnación de los terceros neutrales.

26. Proyecto de artículo 1 (Ámbito de aplicación)

“1. El Reglamento será aplicable cuando las partes en una operación realizada mediante comunicaciones electrónicas, en el momento de la operación, hayan convenido explícitamente que las controversias dimanantes de esa operación y que entren en el ámbito del Reglamento ODR se resolverán recurriendo a la vía ODR en virtud del Reglamento.

[1 bis. El acuerdo explícito mencionado en el párrafo 1) supra requiere un acuerdo independiente de esa operación[, y] que se notifique sin ambigüedades al comprador que toda controversia que surja de la operación y que entre en el ámbito del Reglamento ODR se resolverá exclusivamente mediante un procedimiento ODR de conformidad con el presente Reglamento

⁸ En su 24º período de sesiones, el Grupo de Trabajo convino en mantener en todo el Reglamento la expresión “días de calendario” (A/CN.9/739, párr. 64). El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar su decisión de estipular en un documento adicional la recomendación de que en el Reglamento los plazos han de entenderse de manera liberal para garantizar la equidad para ambas partes, y de que el proveedor de servicios ODR puede establecer sus propias reglas con respecto a los plazos, siempre que no sean incompatibles con el Reglamento (A/CN.9/721, párr. 99).

[y si se aplicará a esa controversia la Modalidad I o la Modalidad II] (la “cláusula sobre solución de controversias”).]

[2. El presente Reglamento se aplicará únicamente cuando se alegue en la demanda:

a) que las mercancías vendidas o arrendadas [o los servicios prestados] no se suministraron, no se suministraron puntualmente, no se cobraron a crédito o a débito correctamente o no se suministraron conforme a lo acordado en el momento de la operación; o

b) que no se recibió el pago íntegro por las mercancías suministradas [o los servicios suministrados].

[3.

Opción 1: [El presente Reglamento no será de aplicación cuando la ley aplicable en el lugar de residencia del comprador disponga que los acuerdos de someter una controversia al Reglamento ODR solamente serán vinculantes para el comprador cuando se hayan concertado después de surgir la controversia y cuando el comprador no haya dado ese consentimiento después de surgir la controversia o no haya confirmado ese acuerdo que expresó en el momento de la operación.]

Opción 2: [El presente Reglamento regirá los procedimientos ODR, con la salvedad de que cuando alguno de los artículos del Reglamento esté en conflicto con una disposición de la ley aplicable que las partes no puedan excluir, tal disposición prevalecerá.]”

Observaciones

Párrafo 1)

27. En los párrafos 1) y 1) *bis* se prevé como requisito que haya acuerdo para someter las controversias a la vía ODR y que ese acuerdo sea independiente de la operación. Se sugirió que si hubiera un acuerdo separado se garantizaría mejor que el consumidor diera su “consentimiento informado” al convenir en someter las controversias a la vía ODR (A/CN.9/744, párrs. 23 y 24). El consentimiento de las partes podría expresarse en forma de una casilla separada (acuerdo *click-wrap*) accesible desde la operación pertinente o vinculado a ella.

Párrafo 1) bis

28. En el párrafo 1) *bis* se ha incluido texto entre corchetes para prever la información necesaria que se ha de ofrecer al comprador en el momento de la operación en relación con la Modalidad del Reglamento que regulará el procedimiento para la solución de controversias.

29. También se ha insertado una definición de la “cláusula sobre solución de controversias” para que la examine el Grupo de Trabajo, ya que en otros lugares del Reglamento se mencionan los requisitos de esa cláusula y la posibilidad de excluirla (véanse por ejemplo el párrafo 3) del proyecto de artículo 2, el párrafo 1) del proyecto de artículo 3, el párrafo 4) del proyecto de artículo 7 y los proyectos de artículo 10 y 11).

30. Se debería incorporar en un apéndice del Reglamento una cláusula modelo sobre solución de controversias para cada Modalidad, que incluyese la determinación de la ley aplicable (véanse los párrafos 68 a 70 del documento A/CN.9/WG.III/119/Add.1).

Párrafo 2)

31. Podría ser conveniente definir en el Reglamento a qué controversias se aplicará. En la redacción actual, el proyecto de párrafo 2) se ocupa de la naturaleza de las posibles demandas que se enunciaron en el documento A/CN.9/WG.III/WP.115; en consecuencia, esa redacción excluye también las demandas cuya resolución por la vía ODR conforme al Reglamento podría ser inadecuada, como las interpuestas por daños emergentes o lesiones corporales.

32. Alternativamente, se podría definir el ámbito de aplicación del Reglamento remitiendo al artículo 4A (Aviso), si se modificase ese artículo para que presentara la lista completa de demandas que se pueden interponer en virtud de Reglamento (véase el párrafo 55 *infra*).

Párrafo 3)

33. Si bien inicialmente las opciones 1 y 2 no se propusieron como variantes, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si dejando solamente una de las opciones quedaría suficientemente claro en el Reglamento que los procedimientos ODR están sujetos a la legislación nacional de protección del consumidor correspondiente, en particular en los Estados en que los consentimientos previos a la controversia para recurrir al arbitraje con consumidores no sean vinculantes para los consumidores.

34. El Grupo de Trabajo tal vez desee tener en cuenta que el Reglamento es de naturaleza contractual y que por ello, no serviría en ningún caso para invalidar el derecho interno.

35. Proyecto de artículo 2 (Definiciones)

“A los efectos del presente Reglamento:

ODR

1. Por “ODR” se entenderá la solución en línea de controversias, que constituye un mecanismo para resolver controversias facilitado mediante el empleo de las comunicaciones electrónicas y demás tecnologías de la información y de las comunicaciones.

2. Por “plataforma ODR” se entenderá una plataforma informática para la solución de controversias consistente en un sistema para la generación, el envío, la recepción, el archivo, el intercambio o toda otra técnica de procesamiento de comunicaciones electrónicas que sea utilizable por la vía ODR y que sea designada por el proveedor de servicios ODR en el procedimiento ODR.

3. Por “proveedor de servicios ODR” se entenderá el proveedor de servicios para la solución de controversias en línea especificado en la cláusula sobre solución de controversias por la que las controversias se someten al procedimiento de solución en línea con arreglo al presente

Reglamento. Un proveedor de servicios ODR es una entidad que se encarga de administrar las actuaciones por vía ODR [y designa una plataforma ODR] [, independientemente de si ese proveedor dispone o no de una plataforma ODR].

Partes

4. Por “demandante” se entenderá toda parte en una controversia que inicie un procedimiento por vía ODR emitiendo un aviso conforme al presente Reglamento.

5. Por “demandado” se entenderá el destinatario del aviso de apertura emitido.

6. Por “tercero neutral” se entenderá toda persona que preste asistencia a las partes en orden al arreglo o solución de la controversia.

Comunicación

7. Por “comunicación” se entenderá toda declaración, exposición, aviso, contestación, presentación, notificación o solicitud que una parte a la que sea aplicable el Reglamento haya de efectuar en el curso de un procedimiento tramitado por ODR.

8. Por “comunicación electrónica” se entenderá toda comunicación que una persona a la que sea aplicable el Reglamento curse por medios de información generados, expedidos, recibidos o archivados por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, entre los que cabe citar, a título no exhaustivo, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telefax, los servicios de mensajes cortos (SMS), las conferencias, charlas y foros por Internet o los microblogs, e incluirá toda información en forma analógica, como los objetos, documentos, imágenes, textos y sonidos a los que se les da formato digital a fin de poder ser procesados directamente por un ordenador u otros aparatos electrónicos.”

Observaciones

Observaciones generales

36. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar el orden en que figuran las definiciones, que se han reorganizado por temas (en vez de dejarlas en estricto orden alfabético), a fin de establecer el mismo orden en todas las versiones en distintos idiomas del Reglamento, conforme a lo solicitado por el Grupo de Trabajo en su 25º período de sesiones (A/CN.9/744, párr. 47).

37. El Grupo de Trabajo tal vez recuerde que, en su 25º período de sesiones, pidió que se agregara a la lista de definiciones del proyecto de artículo 2 una definición del término “escrito”, en relación con el requisito del proyecto de artículo 9 de que el laudo figure por escrito y esté firmado por el tercero neutral (A/CN.9/744, párr. 59). En su 26º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió igualmente (y en relación con el mismo requisito del proyecto de artículo 9), que se insertase en el Reglamento una definición del término “firma” (A/CN.9/762, párr. 44).

38. En un intento por lograr una mayor claridad en el Reglamento, los medios con los que se cumplen los requisitos de que un laudo figure por escrito y esté firmado a

los efectos del proyecto de artículo 9 se han incluido en el propio proyecto de artículo 9, en lugar de definirlos como términos independientes. Ambos términos figuran únicamente en el proyecto de artículo 9 (aunque la expresión “firma electrónica” se utiliza igualmente en los proyectos de artículo 4A y 4B) y tal vez no merezcan una definición independiente en el presente Reglamento.

Párrafos 2) y 3) “Proveedor de servicios ODR”

39. Los párrafos 2) y 3) han sido ligeramente modificados para dejar más claro el vínculo que se presupone entre plataforma ODR y el proveedor de servicios ODR, aunque el Grupo de Trabajo tal vez desee de todos modos analizar si ese vínculo está articulado de un modo suficientemente claro en el Reglamento (véase el párrafo 22 *supra*).

40. El párrafo 3) ha sido modificado, junto con un nuevo proyecto de artículo 11, para que exista en el Reglamento un vínculo entre la cláusula sobre solución de controversias y la determinación del proveedor de servicios ODR. Tal vez se considere conveniente porque, dado que el Reglamento no permite procedimientos “*ad hoc*”, es importante que en el contrato entre las partes se especifique el proveedor de servicios que desempeñará las funciones administrativas contempladas en el Reglamento.

41. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si es necesario especificar si el proveedor de servicios ODR ha de mantener una plataforma ODR o si esa información tendría mejor cabida en un documento en el que se ofreciesen directrices para los proveedores de servicios ODR.

Párrafo 6) “tercero neutral”

42. Se ha modificado ligeramente la definición del tercero neutral con objeto de lograr una redacción más clara y simple.

43. Proyecto de artículo 3 (Comunicaciones)

“1. Todas las comunicaciones intercambiadas en el curso de las actuaciones por ODR serán comunicadas por medios electrónicos al proveedor de servicios ODR por conducto de la plataforma ODR designada por el proveedor de servicios ODR. [La dirección electrónica de la plataforma ODR a la que se pueden transmitir los documentos se especificará en la cláusula sobre solución de controversias.]

2. A fin de poder aplicar el Reglamento, cada parte deberá, [en el momento de dar su acuerdo explícito a que se sometan a ODR en virtud del Reglamento las controversias dimanantes de la operación, también] proporcionar su información de contacto por vía electrónica.

3. [[La dirección electrónica designada] [Las direcciones electrónicas designadas] del demandante, a efectos de todas las comunicaciones que se produzcan en virtud del Reglamento [será] [serán]: [la] [las] [notificada] [notificadas] [por el demandante al proveedor de servicios ODR conforme al párrafo 2) del artículo 3] y que se [haya] [hayan] actualizado y comunicado al proveedor de servicios ODR en cualquier momento posterior durante el procedimiento ODR (inclusive al especificarse en el aviso una dirección electrónica actualizada, si procede)].

4. *[La dirección electrónica] [Las direcciones electrónicas] a efectos de comunicación del aviso por el proveedor de servicios ODR al demandado [será] [serán] [[la] [las] que haya notificado el demandado al proveedor de servicios ODR al aceptar el Reglamento [conforme al párrafo 2) del artículo 3 supra] y que se [haya] [hayan] actualizado y comunicado al demandante o al proveedor de servicios ODR en cualquier momento anterior a la emisión del aviso. Posteriormente, el demandado podrá actualizar su dirección electrónica notificándola al proveedor de servicios ODR en cualquier momento durante el procedimiento ODR.]*

[5. Una comunicación se tendrá por recibida cuando, tras su transmisión al proveedor de servicios ODR de conformidad con el párrafo 1), el proveedor de servicios ODR notifique a las partes que dispone de esa comunicación de conformidad con el párrafo 6). [El tercero neutral podrá, a su discreción, prorrogar cualquier plazo en caso de que el destinatario de una comunicación demuestre que existe una buena razón por la que no puede recuperar esa comunicación desde la plataforma.]

6. El proveedor de servicios ODR comunicará rápidamente los acuses de recibo de comunicaciones electrónicas entre las partes y el tercero neutral a todas las partes [y al tercero neutral] enviándolos a sus respectivas direcciones electrónicas designadas.

7. El proveedor de servicios ODR notificará rápidamente a todas las partes y al tercero neutral toda comunicación electrónica recibida en la plataforma ODR.”

Observaciones

Párrafo 1)

44. En su 25º período de sesiones, el Grupo de Trabajo convino en que el párrafo 1) reflejara el principio de que todas las comunicaciones realizadas durante el proceso ODR se tramitan por la plataforma ODR (A/CN.9/744, párrs. 62 y 63).

45. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar i) cuándo y de qué modo designará el proveedor de servicios ODR una plataforma ODR; y ii) si en la cláusula sobre solución de controversias se debería incluir la dirección electrónica a la que debería remitir un demandante su demanda, o si esa indicación sería prematura. En cualquier caso, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar de qué modo obtendría información sobre la plataforma ODR correspondiente el demandante.

Párrafo 2)

46. En su 25º período de sesiones, el Grupo de Trabajo convino en mantener el párrafo 2), en el que se fija como requisito para recurrir al Reglamento la obligación de que las partes faciliten su información de contacto (A/CN.9/744, párr. 39). En aras de la claridad se han agregado las palabras “por vía electrónica” después de “información de contacto”.

47. Puesto que el párrafo 2) se refiere a la cuestión de la comunicación más que al ámbito de aplicación, se ha trasladado del proyecto de artículo 1 a este párrafo (véase A/CN.9/744 párr. 42 y párrs. 68 a 71). Dado que se expresa como requisito para la aplicabilidad del Reglamento, tal vez sea conveniente un plazo para el

cumplimiento de esa condición (teniendo en cuenta el texto del proyecto de artículo 3). Se ha insertado texto entre corchetes al respecto.

Párrafos 3) y 4)

48. En su 25º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara un proyecto de texto en el que se reflejaran las distintas opciones y formas en que cabría redactar los párrafos 3) y 4) del proyecto de artículo 3 con miras a que fueran examinadas (A/CN.9/744, párr. 71). En respuesta a esa petición, se han vuelto a redactar esos párrafos para regular los casos en que: a) un aviso se transmita en el primer caso a una o varias direcciones electrónicas proporcionadas por el demandado cuando convino en someter las controversias al Reglamento; y b) la dirección o las direcciones electrónicas facilitadas se mantienen constantes y actualizadas durante todo el procedimiento.

49. Como requisito para utilizar el Reglamento, y conforme al párrafo 2), se requiere a ambas partes que comuniquen sus respectivas direcciones electrónicas y por consiguiente, se han suprimido las opciones anteriores que eran incompatibles con esa disposición.

Párrafo 5)

50. En su último período de sesiones, el Grupo de Trabajo decidió que el párrafo 5), que en su enunciado inicial reflejaba el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (“la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas”), debería redactarse de nuevo teniendo presente la estrecha relación de ese párrafo con el párrafo 6), y teniendo en cuenta además el artículo 2 5) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (A/CN.9/744, párr. 73).

51. Por consiguiente, el proyecto de párrafo 5) dice ahora que la comunicación “se tendrá por recibida”, con lo cual se evita la ambigüedad de la redacción anterior en la que se hablaba de que pudiese ser recuperada en el momento en que el proveedor de servicios ODR notifica a las partes que la comunicación pertinente está disponible en la plataforma. Si bien una disposición en la que se considera recibida la comunicación puede trasladar a las partes un riesgo ligeramente superior de no recibir la comunicación, en comparación con una disposición en la que se presume la recepción (dado que la presunción puede rebatirse), puede también ofrecer una mayor certeza temporal.

52. En el proyecto de párrafo 5) se prevé también, entre corchetes, el poder discrecional del tercero neutral de prorrogar los plazos, cuando el destinatario demuestre que existe una buena razón por la que no haya podido recuperar esa comunicación en la plataforma.

2. Apertura del procedimiento

53. Proyecto de artículo 4A (Aviso)

“1. El demandante comunicará un aviso al proveedor de servicios ODR con arreglo al formulario que aparece en el párrafo 4). En lo posible deberá adjuntarse a dicho aviso todo documento u otra prueba en los que el demandante funde su reclamación, o deberá hacerse referencia a ellos.

2. *[El proveedor de servicios ODR deberá comunicar el aviso rápidamente al demandado.] [El proveedor de servicios ODR notificará rápidamente al demandado que el aviso está disponible en la plataforma ODR.]*

3. *El procedimiento por vía ODR se [tendrá por iniciado][iniciará] cuando, tras la comunicación del aviso al proveedor de servicios ODR de conformidad con el párrafo 1), el proveedor de servicios ODR notifique a las partes que el aviso está disponible de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2).*

4. *El aviso deberá contener:*

“a) el nombre y la dirección electrónica designada del demandante y (de haberse nombrado uno) del representante autorizado por el demandante para actuar en su nombre en el curso del procedimiento ODR;

b) el nombre y la dirección electrónica del demandado y (de haberse nombrado uno) del representante del demandado, siempre que el demandante conozca estos datos;

c) los motivos alegados como fundamento de la reclamación presentada;

d) cualquier solución que se proponga para resolver la controversia;

e) una declaración por la que el demandante asegure no haber entablado un procedimiento por ninguna otra vía contra el demandado respecto de la controversia originada por la operación controvertida;

[f) la ubicación del demandante;]

[g) el idioma que prefiere para las actuaciones el demandante;]

[“h) la firma, en forma electrónica, del demandante o del representante del demandante, inclusive cualquier otro método de identificación y de autenticación;]

[...].”

Observaciones generales

54. En su 25º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió que el proyecto de artículo 4 se reestructurara en dos artículos separados, relativos al aviso y a la contestación, respectivamente (A/CN.9/744, párr. 76).

55. Además de los párrafos 10 a 14 del documento A/CN.9/WG.III/WP.113 y de la Sección IV B) del documento A/CN.9/WG.III/WP.115, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la propuesta de adoptar un enfoque consistente en enumerar, en el párrafo 4) del proyecto de artículo 4A y en el párrafo 3) del proyecto de artículo 4B, una lista de posibles demandas y contestaciones a las mismas para incluir en el aviso y en la contestación, respectivamente. Alternativamente, el Grupo de Trabajo puede considerar que en el párrafo 2) del proyecto de artículo 1 se delimita suficientemente el alcance de las demandas que pueden ser apropiadas para la solución de controversias en línea.

56. Se ha eliminado un apartado que figuraba en un proyecto anterior del Reglamento y en el que se exigía al demandante indicar en el momento de transmitir

su aviso si acepta participar en un procedimiento ODR porque podría causar confusión, a la vista del acuerdo que se exige en el momento de la operación en el proyecto de artículo 1.

Párrafo 3)

57. Ese párrafo ha sido ligeramente modificado para ajustar la apertura del procedimiento, que se basa en la recepción del aviso, a las disposiciones sobre el momento en que se tienen por recibidas las comunicaciones que figuran en el párrafo 5) del proyecto de artículo 3. En cualquier caso, el Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si es necesario el párrafo 3), ya que la fecha de apertura del procedimiento no afecta a ninguna otra disposición del Reglamento y si se iniciase un procedimiento paralelo por otra vía, probablemente la excepción de cosa juzgada estaría regulada por el derecho interno.

Párrafo 4)

Apartado e) del párrafo 4)

58. El Grupo de Trabajo tal vez desee tener en cuenta que, en su 23º período de sesiones, se estimó que el apartado e) del párrafo 4), junto con la disposición homóloga del apartado e) del párrafo 3) del proyecto de artículo 4B, tal vez podrían contribuir a impedir una multiplicidad de procedimientos relacionados con la misma controversia (véase A/CN.9/721, párr. 122).

Apartado f) del párrafo 4)

59. El Grupo de Trabajo tal vez desee sopesar si la ubicación del demandante tiene alguna utilidad práctica, ya que puede no ser un indicador del idioma ni de la jurisdicción pertinente.

Apartado g) del párrafo 4)

60. El apartado g) del párrafo 4) ha sido modificado ligeramente con objeto de aclarar que el idioma preferido que se especifica en esta etapa es el del demandante. Se ha introducido la modificación correspondiente en el apartado f) del párrafo 3) del proyecto de artículo 4B, a fin de reflejar la petición del Grupo de Trabajo (recogida en el proyecto de artículo 12) de que el idioma de las actuaciones debe ser acordado por las partes en el momento de apertura del procedimiento ODR.

Apartado h) del párrafo 4)

61. El Grupo de Trabajo quizá desee recordar que en su 22º período de sesiones, observó que tal vez no fuese necesario utilizar métodos complejos de identificación y autenticación a los fines de la ODR, y que en los textos actuales de la CNUDMI sobre el comercio electrónico ya se contemplaban métodos de firma electrónica que eran fiables y adecuados a los fines para los que se utilizaban (artículo 7 2) b) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico; véase A/CN.9/716, párr. 49). Tal vez sería más apropiado ocuparse de la identificación y la autenticación de las partes en procedimientos ODR en un documento que no fuese el Reglamento, como las directrices y normas mínimas para los proveedores de servicios ODR. Conviene señalar también que el concepto de “firma electrónica”

difiere del de “firma digital”. La firma electrónica⁹ designa todo tipo de firmas que sirvan para identificar y autenticar al usuario, inclusive la gestión de los datos de identidad¹⁰.

62. Proyecto de artículo 4B (Contestación)

“1. El demandado comunicará al proveedor de servicios ODR su contestación al aviso mediante el formulario consignado en el párrafo 3) dentro de los [siete (7)] días de calendario siguientes a la fecha de recepción del aviso. El demandado deberá adjuntar a su contestación, en lo posible, cualquier documento u otra prueba en la que funde su defensa, o deberá hacer referencia a ellos.

[2.

[Opción 1: El demandado, en respuesta al aviso, podrá comunicar al proveedor de servicios ODR por conducto de la misma plataforma ODR del mismo procedimiento una demanda derivada de la misma operación señalada por el demandante en el aviso (“la contrademanda”).] La contrademanda deberá comunicarse a más tardar [siete (7)] días de calendario [después de que el aviso de la demanda del demandante haya sido comunicado al proveedor de servicios ODR. [La contrademanda será dirimida en el procedimiento ODR junto con la demanda del demandante.]

[En la contrademanda deberá indicarse la información mencionada en los apartados c) y d) del párrafo 4) del artículo 4A].]”

[Opción 2: “El demandado, en respuesta al aviso, podrá comunicar una contrademanda al proveedor de servicios ODR. Por “contrademanda” se entenderá una demanda [independiente] formulada por el demandado contra el demandante basada en la misma operación indicada por el demandante en el aviso [y dirigida al mismo proveedor de servicios ODR]].] La contrademanda deberá comunicarse a más tardar [siete (7)] días de calendario después de que el aviso de la demanda del demandante haya sido comunicado al proveedor de servicios ODR. La contrademanda será dirimida en el procedimiento ODR junto con la demanda del demandante.]

⁹ En el apartado a) del artículo 2 de la Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas se define la firma electrónica como “los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos y para indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos”. En las firmas digitales se suelen emplear tecnologías criptográficas como la infraestructura de clave pública, que, para ser eficaz, requiere tecnologías y medios de aplicación específicos.

¹⁰ La gestión de los datos de identidad podría definirse como un sistema de procedimientos, políticas y tecnologías encaminado a gestionar el período de validez y los derechos de los usuarios y sus credenciales electrónicas. Se explicó que la verificación de la identidad de una persona o entidad que trate de entrar a distancia en un sistema, que tenga la autoría de una comunicación electrónica, o que firme un documento electrónico, entraba en el ámbito de lo que ha venido denominándose la “gestión de los datos de identidad”. Las funciones de la gestión de los datos de identidad se cumplen mediante tres procesos: la identificación, la autenticación y la autorización (véase A/CN.9/692 y A/CN.9/728).

[En la contrademanda deberá indicarse la información mencionada en los apartados c) y d) del párrafo 4) del artículo 4A].]”

3. *La contestación deberá contener:*

a) el nombre y la dirección electrónica designada del demandado y (de haberse nombrado uno) del representante autorizado por el demandado para actuar en su nombre en el curso del procedimiento ODR;

b) la contestación a la demanda y a los alegatos formulados en el aviso;

c) cualquier solución que se proponga para resolver la controversia;

d) una declaración por la que el demandado asegure no haber entablado un procedimiento por ninguna otra vía contra el demandante respecto de la controversia originada por la operación controvertida;

[e) la ubicación del demandado];

[f) si acepta el idioma de las actuaciones indicado por el demandante de acuerdo con el apartado g) del párrafo 4) del artículo 4A supra o si prefiere otro;]

[g) la firma, en forma electrónica, del demandado o del representante del demandado, inclusive cualquier otro método de identificación y de autenticación;]

[...].”

Observaciones generales

63. Se ha eliminado una disposición que figuraba en un proyecto anterior del Reglamento en la que se exigía al demandado indicar en el momento de la contestación si acepta participar en un procedimiento ODR porque podría causar incertidumbre, a la vista del acuerdo que se exige en el momento de la operación en el proyecto de artículo 1.

Párrafo 2)

64. El párrafo 2) del proyecto de artículo 4B refleja la decisión del Grupo de Trabajo de incluir en el Reglamento una disposición que rija las contrademandas (A/CN.9/739, párr. 93).

65. En su 24º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara una definición de contrademanda, como variante de lo propuesto en la opción 1, y que además sugiriera en qué lugar del Reglamento habría que insertar esa definición (A/CN.9/739, párr. 93). Por consiguiente, se ha insertado la opción 2 entre corchetes. El Grupo de Trabajo tal vez desee mantener en el texto la definición independiente propuesta en la opción 2 de este párrafo, o bien insertarla, por separado, en el proyecto de artículo 2 (Definiciones).

66. Además de analizar si la redacción actual de la definición sería lo bastante amplia como para englobar las contrademandas en las controversias entre empresas, el Grupo de Trabajo tal vez desee analizar las cuestiones siguientes:

a) ¿Debe el demandado presentar una nueva demanda o incluir la contrademanda en su contestación? En ese último caso, ¿debe ajustarse la contrademanda al formulario del proyecto de artículo 4A?

b) ¿Puede presumirse que la contestación al aviso contiene una contrademanda si no hay una declaración o indicación explícita por parte del demandado de que está formulando esa contrademanda? ¿Tendrá el tercero neutral discreción para decidir que una contestación incluye o constituye una contrademanda en ausencia de una declaración explícita a ese efecto?

c) ¿Tendrá el demandante ocasión de contestar a la contrademanda o tendrá el tercero neutral discreción para solicitar al demandante que lo haga?

d) ¿Cómo se determinará si la contrademanda entra en el ámbito de la demanda inicial enunciada en el aviso del demandante? (A/CN.9/739, párr. 92). El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar en qué medida se resuelve esa cuestión en el párrafo 4) del proyecto de artículo 7 (facultad del tercero neutral para dictaminar acerca de su propia competencia jurisdiccional, inclusive sobre la existencia o la validez del acuerdo para someter la controversia a un procedimiento ODR);

e) ¿La presentación de una contrademanda impide al demandado presentar una nueva demanda sobre la misma operación a otro proveedor de servicios ODR distinto en la práctica?

Párrafo 3)

67. El párrafo 3) trata del contenido de la contestación al aviso y refleja las disposiciones del párrafo 4) del proyecto de artículo 4A.

Apartado a) del párrafo 3)

68. Al igual que en el párrafo 4) del proyecto de artículo 4A, habría que tomar en consideración el tema de la protección de los datos o de la vida privada y de la seguridad de los medios informáticos en el contexto de la comunicación de información relativa a las partes durante un procedimiento ODR (A/CN.9/721, párr. 108).

Apartado f) del párrafo 3)

69. El apartado f) del párrafo 3) ha sido modificado ligeramente para ajustarlo a la redacción solicitada por el Grupo de Trabajo para el proyecto de artículo 12 (Idioma de las actuaciones), en el que se indica que el idioma de las actuaciones será acordado por las partes en el momento de la apertura del procedimiento ODR (véase también el párrafo 60 *supra*).

(A/CN.9/WG.III/WP.119 y Add.1) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 27º período de sesiones

ADICIÓN

Índice

B.	Notas sobre el proyecto de reglamento (<i>continuación</i>)
3.	Negociación
4.	Tercero neutral
5.	Arreglo facilitado
6.	Decisión
7.	Arbitraje
8.	Disposiciones generales

B. Notas sobre el proyecto de reglamento (*continuación*)

3. Negociación

1. Proyecto de artículo 5 (Negociación y arreglo)

Negociación

“1. [Tras la comunicación de la contestación [y, si procede, de la contrademanda] a que se hace referencia en el artículo 4B al proveedor de servicios ODR [y de la notificación de esta al demandante]], las partes tratarán de arreglar su controversia mediante negociaciones directas, incluso, en su caso, mediante los métodos de comunicación que ofrezca la plataforma ODR.]

2. Si el demandado no comunica al proveedor de servicios ODR su contestación al aviso mediante el formulario consignado en el párrafo 3) del artículo 4B en un plazo de siete (7) días de calendario, se presumirá que ha rechazado la invitación a negociar y el procedimiento ODR pasará automáticamente a la etapa del arreglo facilitado, en cuyo momento el proveedor de servicios ODR deberá proceder rápidamente al nombramiento de un tercero neutral con arreglo a lo previsto en el artículo 6 (Nombramiento de un tercero neutral).

3. Si las partes no han arreglado su controversia mediante la negociación en el plazo de diez (10) días de calendario contados a partir de la presentación de la contestación a la plataforma ODR [y de la notificación de esta al demandante], el procedimiento ODR pasará automáticamente a la etapa del arreglo facilitado, en cuyo momento el proveedor de servicios ODR

deberá proceder rápidamente al nombramiento de un tercero neutral con arreglo a lo previsto en el artículo 6 (Nombramiento de un tercero neutral).

4. Las partes podrán convenir en prorrogar una vez el plazo para [presentar la contestación] [llegar a un arreglo]. No obstante, dicha prórroga no podrá exceder de diez (10) días de calendario.

Arreglo

5. Si se llega a un arreglo [durante la etapa de negociación] [o en cualquier otra etapa del procedimiento ODR], [se consignarán las condiciones de ese arreglo en la plataforma ODR], [en cuyo momento,] se dará automáticamente por concluido el procedimiento ODR.”

Observaciones generales

2. Se ha cambiado el orden de las disposiciones del proyecto de artículo 5, teniendo en cuenta las propuestas del Grupo de Trabajo en su 25º período de sesiones y con miras a reflejar más claramente la cronología probable de la negociación y el arreglo (véase A/CN.9/WG.III/WP.117/Add.1, párrafo 2). El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de incorporar los subencabezamientos provisionales insertados en este artículo para distinguir mejor entre las etapas de negociación y de arreglo, en particular si se inclina a considerar que el arreglo es un proceso que puede tener lugar en cualquier momento durante el curso del procedimiento, incluso en la etapa del arreglo facilitado o antes de que finalice cualquier etapa en la que se adopten decisiones (sin embargo, véase A/CN.9/744, párrafo 85).

3. En relación con la etapa del arreglo, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar además aspectos técnicos relativos a la formación de los acuerdos de arreglo, entre otras cosas, si estos exigirían una disposición separada para las controversias dimanantes del arreglo. Se ha eliminado un párrafo que figuraba en un proyecto anterior del Reglamento en el cual se preveía la posibilidad de reabrir o recomenzar el procedimiento si no se cumpliese el arreglo, ya que era incompatible con los principios del derecho en virtud de los cuales los acuerdos de arreglo equivalen a contratos que deben ser ejecutados de acuerdo con las condiciones del contrato y además porque mezclaba la ejecución de un arreglo con otras etapas del procedimiento ODR (a saber, el pronunciamiento de la decisión o el laudo).

Párrafo 1)

4. En su 25º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que modificara la redacción del párrafo 1) a fin de tener en cuenta las propuestas de que se definiera con más claridad la etapa de la negociación y, además, de que el Reglamento apoyara la aplicación de los arreglos negociados (A/CN.9/744, párrafos 79 a 81). En consecuencia, el párrafo 1) se ocupa ahora del momento y el contenido de la etapa de negociación. En ese párrafo anteriormente se preveían las consecuencias del arreglo (a saber, la conclusión del procedimiento), que ahora figuran en el proyecto de párrafo 5).

Párrafos 2) y 3)

5. En los párrafos 2) y 3) se prevé que, en diferentes circunstancias, el procedimiento ODR pase a la etapa siguiente (arreglo facilitado). Esa etapa sería la misma en las dos Modalidades (A/CN.9/WP.119, párrafos 15 a 20). Por ello, se ha eliminado el texto anterior que se refería a las etapas del procedimiento posteriores a la del arreglo facilitado, ya que se consideraba innecesario y que podía llevar a confusión.

6. En el párrafo 2) se han sustituido las palabras “[contestar al aviso]” por “comunica al proveedor de servicios ODR su contestación al aviso mediante el formulario consignado en el párrafo 3) del artículo 4B” con objeto de hacerlas compatibles con los requisitos del aviso establecidos en el proyecto de artículo 4B, así como también para evitar ambigüedades en relación con el momento de la recepción (véase A/CN.9/WP.119, párrafo 21).

7. En el párrafo 3) se ha incorporado texto entre corchetes para aclarar el momento de la recepción de la contestación y en aras de la uniformidad con las demás disposiciones de ese artículo.

8. También se ha añadido nuevo texto en el párrafo 3) para aclarar la etapa en la que se nombraría al tercero neutral.

Párrafo 4)

9. En el 25º período de sesiones del Grupo de Trabajo se señaló que sería preferible limitar el período durante el cual pudiera acordarse una prórroga con miras a reforzar la eficiencia del procedimiento; se convino en que bastaría con un plazo de diez días (A/CN.9/744, párrafos 84 y 86).

10. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si la intención de este párrafo es prorrogar el plazo para presentar una contestación (conforme al proyecto de artículo 4B) o para llegar a un arreglo (conforme al párrafo 5 del proyecto de artículo 5). Aunque esas opciones no son mutuamente excluyentes, el Grupo de Trabajo tal vez desee recordar el consenso a que había llegado en el sentido de que solo habría que emplear una de esas variantes (A/CN.9/744, párrafo 85). Se deliberó acerca de la posibilidad de que el párrafo 4) rigiera únicamente la apertura del procedimiento y, por consiguiente, se aplicara únicamente a la contestación, o de que, por el contrario, restringiera la posibilidad de que las partes negociaran mediante el sistema ODR limitando el plazo en que pudieran llegar a un arreglo mediante esas negociaciones (sin perjuicio de su posibilidad de negociar, en cualquier caso, al margen del sistema ODR) (A/CN.9/744, párrafo 85).

Párrafo 5)

11. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si se puede alcanzar un arreglo en cualquier etapa del procedimiento ODR, en cuyo caso podría ser aconsejable incluir el arreglo en un proyecto de artículo independiente, a fin de distinguirlo del proceso de negociación (véase el párrafo 2 *supra*).

12. El Grupo de Trabajo manifestó preferencia por que los arreglos quedaran claramente consignados en la plataforma ODR (A/CN.9/744, párrafo 90). Por ello, se podría considerar la posibilidad de incluir, en las Directrices para terceros neutrales y proveedores de servicios ODR, disposiciones sobre cuánto tiempo se

mantendrían en la plataforma o en los registros del proveedor de servicios ODR esos acuerdos de arreglo y se podrían examinar cuestiones de confidencialidad y otras consideraciones; y a ese respecto, el Grupo de Trabajo tal vez desee decidir si la expresión “en la plataforma ODR” que figura en el párrafo 5) permite una flexibilidad suficiente en relación con el registro que ha de mantener el proveedor de servicios ODR.

13. Además, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar aspectos técnicos relativos a la formación de los acuerdos de arreglo, entre otras cosas, si se necesitaría al respecto una disposición independiente sobre las controversias dimanantes del arreglo.

4. Tercero neutral

14. Proyecto de artículo 6 (Nombramiento de un tercero neutral)

“1. El proveedor de servicios ODR nombrará a un tercero neutral [seleccionado de una lista de terceros neutrales cualificados que deberá llevar el proveedor de servicios ODR [o que provenga de otras instituciones arbitrales]] y deberá notificar rápidamente ese nombramiento a las partes.

[2. Se considerará que todo tercero neutral, al aceptar su nombramiento, se compromete a dedicar el tiempo suficiente al procedimiento ODR para cumplirlo sin dilación y conforme al Reglamento.]

3. El tercero neutral declarará su independencia y deberá dar a conocer al proveedor de servicios ODR toda circunstancia [que se plantee en cualquier momento en el curso del procedimiento ODR] que pueda suscitar dudas fundadas acerca de su imparcialidad o de su independencia. El proveedor de servicios ODR deberá comunicar esa información a las partes.

[4. Si, a raíz de su participación en la facilitación del arreglo, un tercero neutral llegara a abrigar dudas de si podría mantenerse imparcial o independiente durante el resto del procedimiento ODR de conformidad con el artículo 8 bis) o el artículo 9, ese tercero neutral [presentará su renuncia e informará en consecuencia a las partes y al proveedor de servicios ODR] [lo hará saber al proveedor de servicios ODR]. El proveedor de servicios ODR deberá comunicar rápidamente esa información a las partes.]

5. Toda parte podrá impugnar el nombramiento del tercero neutral dentro de los [dos (2)] días de calendario siguientes [i)] a la notificación del nombramiento [sin indicar los motivos] [; o ii) a haberse enterado de un hecho o asunto que pueda suscitar dudas fundadas sobre la imparcialidad o la independencia del tercero neutral, [incluidas la declaración o la comunicación del tercero neutral conforme a lo dispuesto en el párrafo 3) [o 4)]] [señalando el hecho o el asunto que ha suscitado esas dudas,] en cualquier momento en el curso del procedimiento ODR].

5 bis. Cuando una parte se oponga al nombramiento de un tercero neutral [con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 i) supra], ese tercero neutral quedará automáticamente descalificado y el proveedor de servicios ODR nombrará a otro en su lugar. Cada una de las partes podrá oponerse [tres (3)] veces, como máximo, al nombramiento de un tercero neutral tras recibir cada aviso de su nombramiento, después de lo cual el nombramiento del tercero neutral por el proveedor de servicios ODR será definitivo [, a reserva de lo dispuesto en

el párrafo 5 ii) supra]. [Por otra parte, si no se presentan objeciones dentro de los dos (2) días siguientes al aviso del nombramiento, este será definitivo, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 5 ii) supra.] [Cuando una parte se oponga al nombramiento de un tercero neutral con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 ii) supra, [el proveedor de servicios ODR] determinará en un plazo de [tres (3)] días de calendario si ese tercero neutral habrá de ser sustituido].

[6. Cada una de las partes podrá expresar sus reparos, en el plazo de tres (3) días de calendario contados a partir del nombramiento definitivo del tercero neutral, a que el proveedor de servicios ODR suministre a ese tercero neutral información generada durante la etapa de negociación. Tras cumplirse ese plazo de tres días, y si no hay objeciones, el proveedor de servicios ODR transmitirá al tercero neutral toda la información existente en la plataforma ODR.]

7. Si se ha de sustituir a un tercero neutral en el curso del procedimiento ODR, el proveedor de servicios ODR, a través de la plataforma ODR, procederá a nombrar a otro tercero neutral que lo sustituya [conforme a lo dispuesto en el párrafo 1)] [y a informar a las partes rápidamente de esa elección]. El procedimiento ODR se reanudará a partir del momento en que el tercero neutral sustituido haya dejado de cumplir sus funciones.

8. Solamente habrá un tercero neutral [, salvo que las partes decidan otra cosa].”

Observaciones

Párrafo 1)

15. Se sugirió incluir entre corchetes los términos “o que provenga de otras instituciones arbitrales” a fin de facilitar el acceso a un mayor número de terceros neutrales, incluso a los que provengan de instituciones arbitrales (A/CN.9/744, párrafo 103). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar i) si se alentará a los proveedores de servicios ODR (en el marco de un documento de directrices) a llevar listas de terceros neutrales y el objetivo de esas listas; ii) en caso afirmativo, si permitir que se escojan terceros neutrales que “provengan de otras instituciones arbitrales” menoscabaría el objetivo de mantener una lista de terceros neutrales; y iii) si los proveedores de servicios ODR no hubiesen de llevar listas de terceros neutrales cualificados, si se debería suprimir la oración “[seleccionado de una lista de terceros neutrales cualificados que deberá llevar el proveedor de servicios ODR [o que provenga de otras instituciones arbitrales]]”.

16. El Grupo de Trabajo tal vez desee tener en cuenta que los términos “y deberá notificar rápidamente ese nombramiento a las partes” anteriormente se hallaban (con una redacción ligeramente diferente) en otra parte del artículo, pero han sido trasladados al párrafo 1) a fin de aclarar la cronología de la comunicación del nombramiento de un tercero neutral a las partes.

Párrafo 2)

17. El párrafo 2) del proyecto de artículo 6 se trasladó desde el párrafo 1) del proyecto de artículo 7, al haber determinado el Grupo de Trabajo que ese párrafo guardaba una mayor relación con el nombramiento del tercero neutral (A/CN.9/744, párrafo 104).

Párrafo 3)

18. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar su propuesta de dar la idea de que la obligación de independencia e imparcialidad del tercero neutral sea de carácter permanente (A/CN.9/744, párrafo 92).

Párrafo 4)

19. El párrafo 4) se ha trasladado del proyecto de artículo 8 al proyecto de artículo 6, que trata del nombramiento del tercero neutral, con objeto de que siga siendo aplicable a la Modalidad I y la Modalidad II¹. Además, el párrafo 4) es coherente con las demás disposiciones del proyecto de artículo 6 relativas a la imparcialidad del tercero neutral y, en su caso, el procedimiento para nombrar a un nuevo tercero neutral. A ese respecto, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si, cuando un tercero neutral llegara a abrigar dudas de si podría mantenerse imparcial o independiente, debería presentar su renuncia o comunicar esa información al proveedor de servicios ODR, en cuyo caso la aplicación del punto ii) del párrafo 5) se dejaría al criterio de la parte. Se ha insertado texto en el que se dispone esa última opción, de modo que en lugar de presentar su renuncia solamente en función de sus dudas, se obligaría al tercero neutral a comunicar al proveedor de servicios ODR la información que originase esas dudas, de resultas de lo cual las partes podrían oponerse conforme a los procedimientos establecidos en el párrafo 5).

Párrafo 5)

20. En su 25º período de sesiones el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que en el proyecto de artículo 6 redactara una disposición por separado en virtud de la cual una parte pudiera oponerse al nombramiento de un tercero neutral en cualquier etapa del procedimiento, siempre y cuando esa objeción estuviera justificada (A/CN.9/744, párrafo 94). En consecuencia, el antiguo párrafo 3) se dividió en dos párrafos, 5) y 5) *bis*, para diferenciar entre el derecho de una parte a impugnar el nombramiento de un tercero neutral en cualquier momento y las consecuencias de esa impugnación.

21. Las partes tienen dos posibilidades para impugnar un tercero neutral. Conforme a la primera, enunciada en el párrafo 5 i), cualquiera de las partes puede impugnar un nombramiento inmediatamente después de que se haya notificado. En ese caso, el tercero neutral será sustituido automáticamente.

22. Conforme a la segunda, enunciada en el párrafo 5 ii), cualquiera de las partes puede impugnar el nombramiento de un tercero neutral en cualquier momento en el curso del procedimiento si se suscitan dudas fundadas sobre la independencia de ese tercero neutral y dentro de los dos días siguientes a que se entere de los hechos que suscitan esas dudas. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar i) si es suficiente un plazo de dos días; ii) si la parte impugnadora debería demostrar objetivamente la existencia de ese hecho o asunto justificatorio (véase el documento A/CN.9/744, párrafo 94, así como el texto relativo a la obligación permanente de informar impuesta al tercero neutral en los párrafos 3) y 4) del proyecto de artículo 6); iii) en ese caso, si se necesitaría adoptar una decisión sobre la sustitución del tercero neutral; y iv) si se necesitase una decisión, si el tercero neutral de que se tratase

¹ Aunque con una ligera modificación necesaria para eliminar “artículo 8 *bis*)” de ese párrafo si fuese aplicable la Modalidad I y eliminar “artículo 9” si fuese aplicable la Modalidad II.

estaría facultado para adoptar esa decisión sobre la impugnación (teniendo presente la actual disposición sobre la propia competencia que figura en el párrafo 4) del artículo 7).

23. Con respecto al punto iv) *supra*, si se considera que el tercero neutral no es la persona adecuada para adoptar esa decisión, una cuestión que habría que examinar es si la responsabilidad de esa decisión corresponde al proveedor de servicios ODR. Se ha insertado texto en la última oración del párrafo 5) *bis* para dar cabida a esa decisión. Alternativamente, esta podría ser una cuestión que resolviesen un mecanismo de revisión interno del proveedor de servicios ODR (véase el proyecto de artículo 9 *ter*)) o directrices o reglas para los proveedores de servicios ODR.

24. El párrafo 5) *bis* ha sido ligeramente modificado para incluir una referencia al “nombramiento definitivo” del tercero neutral (a reserva de la obligación permanente del tercero neutral de hacer saber la información que ponga en tela de juicio su imparcialidad), con objeto de aclarar en qué momento surte efectos el párrafo 6).

Párrafo 6)

25. El párrafo 6) se enmendó a fin de reflejar el principio de que las partes dispondrían de un plazo de tres días para oponerse a la entrega de información al tercero neutral, pero que, una vez expirado ese plazo, toda la información se haría llegar al tercero neutral (A/CN.9/744, párrafo 97).

Párrafo 7)

26. El primer texto entre corchetes se ha incluido para reflejar que cualquier nuevo nombramiento ha de hacerse también de la lista de terceros neutrales mencionados en el párrafo 1) y que se notificará en consecuencia a las partes.

Párrafo 8)

27. En su 25º período de sesiones, el Grupo de Trabajo convino en mantener la redacción del párrafo 8), ya que resultaba claro y permitía al mismo tiempo cierto grado de flexibilidad (A/CN.9/744, párrafos 101 y 102). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar i) si en controversias de poco valor sería apropiado o necesario contar con más de un tercero neutral; y ii) si la redacción actual del Reglamento permite más de un tercero neutral. En relación con el punto ii), habría que responder a las preguntas siguientes: ¿cómo y dónde acordarían las partes contar con más de un tercero neutral? ¿Cómo se comunicarían entre sí los terceros neutrales? Si las partes nombrasen un número par de terceros neutrales, ¿cómo se adoptarían las decisiones en caso de empate? Cuando el Reglamento dispone que el tercero neutral realice determinada función (por ejemplo, recabar información de las partes), ¿tendrían que desempeñar esa función todos los terceros neutrales si se nombra más de uno?

28. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si ubicar el párrafo 8) inmediatamente después del párrafo 1) serviría para establecer una cronología más lógica.

29. Proyecto de artículo 7 (Poderes del tercero neutral)

“[1. A reserva de lo dispuesto en el presente Reglamento [y en las directrices y requisitos mínimos para terceros neutrales en la vía ODR], el tercero neutral podrá dirigir el procedimiento ODR como lo estime oportuno.]

[1 bis. El tercero neutral en ejercicio de sus funciones previstas en el presente Reglamento, dirigirá el procedimiento ODR evitando demoras o gastos innecesarios y cumpliendo un proceso justo y eficiente para resolver el litigio. A esos efectos, el tercero neutral deberá mantenerse en todo momento totalmente independiente e imparcial y deberá tratar a las dos partes en pie de igualdad.]

2. A reserva de cualesquiera objeciones previstas en el párrafo 6) del artículo 6, el tercero neutral dirigirá el procedimiento ODR sobre la base de los documentos presentados por las partes y de toda comunicación enviada por ellas al proveedor de servicios ODR, cuya importancia para el caso será determinada por el tercero neutral. [El procedimiento ODR se sustanciará únicamente sobre la base de la documentación presentada, a menos que el tercero neutral decida otra cosa.]

3. En todo momento durante el curso del procedimiento, el tercero neutral podrá [exigir] [pedir] o permitir a las partes (conforme a las condiciones en materia de costas y otros gastos que el tercero neutral determine) que facilite datos suplementarios, o que presente otros documentos o pruebas, dentro del plazo que determine el tercero neutral.

4. El tercero neutral estará facultado para dictaminar acerca de su propia competencia jurisdiccional y respecto de toda objeción que le sea presentada acerca de la existencia o validez del acuerdo por el que la controversia haya sido remitida a la vía ODR. Para ese fin, se entenderá que toda cláusula sobre solución de controversias que forme parte de un contrato constituye un acuerdo independiente de las demás condiciones del mencionado contrato. Que el tercero neutral determine la nulidad de dicho contrato no supondrá automáticamente que la cláusula sobre solución de la controversia sea, a su vez, inválida.

[5. Cuando el tercero neutral considere que puede haber dudas de que el demandado haya recibido el aviso conforme al Reglamento, hará las averiguaciones o adoptará las medidas que considere necesarias para cerciorarse de que lo haya recibido y, con ese fin, podrá ampliar todo plazo establecido en el Reglamento, si lo considera necesario. [De que alguna de las partes haya recibido cualquier otra comunicación en el curso del procedimiento ODR, el tercero neutral podrá hacer las averiguaciones o adoptar las medidas que considere necesarias para cerciorarse de que la haya recibido, y con ese fin, podrá ampliar todo plazo establecido en el Reglamento, si lo considera necesario.]]”

Observaciones**Párrafos 1) y 1) bis**

30. En los párrafos 1) y 1) bis (el antiguo párrafo 2)) se describen i) las funciones del tercero neutral; y ii) la discrecionalidad amplia del tercero neutral en lo que

respecta a dirigir el procedimiento ODR como lo considere oportuno, a reserva de algunas restricciones (véase A/CN.9/744, párrafo 105).

31. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si en el párrafo 1) se debería incorporar expresamente un documento que se prepararía en relación con las directrices y los requisitos mínimos para los terceros neutrales (véase A/CN.9/WG.III/WP.114) como norma a la que debería estar supeditado el tercero neutral al dirigir el procedimiento.

Párrafo 2)

32. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar el acuerdo a que llegó en el sentido de que el párrafo 2) debería estar supeditado a la posibilidad de una parte de oponerse a la entrega por el proveedor de servicios ODR al tercero neutral de la información generada durante la etapa de negociación del procedimiento ODR (A/CN.9/744, párrafo 108).

33. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la posibilidad de suprimir la última oración del párrafo 2), ya que no confiere poderes adicionales al tercero neutral ni sirve tampoco para excluir la potestad del tercero neutral en la práctica. Además, puede ser considerada ligeramente confusa puesta al lado de lo que dice el párrafo 3).

Párrafo 3)

34. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar que había estudiado la posibilidad de modificar ligeramente los poderes del tercero neutral a fin de permitirle que solicitara, pero no exigiera, a las partes que facilitaran datos suplementarios (A/CN.9/744, párrafo 109).

35. El Grupo de Trabajo tal vez desee también analizar si la disposición sobre las costas podría ser incompatible con la redacción actual del proyecto de artículo 15.

Párrafo 5)

36. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar su solicitud a la Secretaría de que volviera a redactar el párrafo 5) (antiguo párrafo 6)) a fin de obligar al tercero neutral a que hiciera averiguaciones cuando hubiera dudas sobre la recepción del aviso, y conferir al tercero neutral la facultad de hacerlo respecto de todas las demás comunicaciones (A/CN.9/744, párrafos 115 a 117). El texto entre corchetes se insertó en respuesta a esa solicitud.

5. Arreglo facilitado

37. Proyecto de artículo 8 (Arreglo facilitado)

“1. El tercero neutral se comunicará con las partes para tratar de llegar a un acuerdo (“arreglo facilitado”). Si las partes llegan a un acuerdo de arreglo, ese acuerdo se consignará en la plataforma ODR, [y en ese momento] se dará automáticamente por concluido el procedimiento ODR.

Modalidad I

2. Cuando las partes no hayan arreglado su controversia mediante el arreglo facilitado [en el plazo de diez (10) días de calendario a partir del

nombramiento del tercero neutral] (la “expiración de la etapa del arreglo facilitado”), el procedimiento ODR pasará automáticamente a la etapa del arbitraje, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.

Modalidad II

Opción 1:

2. *Cuando las partes no hayan arreglado su controversia mediante el arreglo facilitado [en el plazo de [diez (10)] días de calendario a partir del nombramiento del tercero neutral], el procedimiento ODR se dará automáticamente por terminado.*

Opción 2:

2. *Cuando las partes no hayan arreglado su controversia mediante el arreglo facilitado [en el plazo de [diez (10)] días de calendario a partir del nombramiento del tercero neutral] (la “expiración de la etapa del arreglo facilitado”), el procedimiento ODR pasará automáticamente a la etapa definitiva de las actuaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 bis)."*

Observaciones generales

38. El texto anterior en el que se establecía un mecanismo para desencadenar la etapa siguiente del procedimiento si el arreglo facilitado no desemboca en un acuerdo de arreglo ha sido sustituido, en relación con la Modalidad I, por un mecanismo para el inicio del arbitraje, y en relación con la Modalidad II, por dos opciones para que las examine el Grupo de Trabajo.

39. La etapa del arreglo facilitado se ha definido en el párrafo 1), con objeto de definir más claramente esa segunda etapa del procedimiento. También se ha definido el final de la etapa del arreglo facilitado como la expiración del plazo de diez días de calendario contados a partir del nombramiento del tercero neutral, a fin de proporcionar un mecanismo para pasar a la siguiente etapa del procedimiento por el simple transcurso del tiempo.

Párrafo 1)

40. En lugar de los términos “arreglo” o “acuerdo”, que aparentemente se utilizaban de modo indistinto en este párrafo, se ha insertado la expresión “acuerdo de arreglo”.

41. En el párrafo 1) se insertó texto entre corchetes para reflejar el texto relativo al arreglo que figura en el párrafo 5) del proyecto de artículo 5. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la conveniencia de prever otra opción, que consistiera sencillamente en señalar que si se llegara a un arreglo se aplicarían las disposiciones correspondientes del párrafo 5) del proyecto de artículo 5.

Párrafo 2)

42. Como mecanismo que desencadena la etapa siguiente del procedimiento, el párrafo 2) necesariamente exigiría redacciones diferentes para la Modalidad I (vía arbitral) y la Modalidad II (vía no arbitral). En consecuencia, se ha suprimido en la versión de la Modalidad II del Reglamento el texto anterior que permitía el paso automático a la etapa del arbitraje (A/CN.9/762, párrafo 22).

43. En relación con la Modalidad II, se han incluido dos opciones para que las examine el Grupo de Trabajo. En la primera opción, el procedimiento terminaría una vez que ha expirado la etapa del arreglo facilitado, si aún no se ha alcanzado ningún acuerdo de arreglo.

44. La segunda opción permitiría que se dictase una decisión no vinculante y que su ejecución quedase sujeta a mecanismos privados de ejecución como sellos de confianza. A ese respecto, el Grupo de Trabajo tal vez desee recordar el apoyo que manifestó en su 26º período de sesiones a que se considerase la posibilidad de una “tercera modalidad” que permitiese que el tercero neutral pronunciara una decisión que hiciera exigible mediante mecanismos de ejecución privados las decisiones no vinculantes (A/CN.9/762, párrafos 19 y 20).

45. Si bien en teoría se podría idear una “Modalidad III” para el Reglamento a fin de dar cabida a las dos opciones enunciadas en los párrafos 43 y 44 *supra*, el Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si crear tres conjuntos distintos de artículos no podría hacer demasiado compleja la comprensión del Reglamento y hacerlo así menos fácil de manejar.

46. Si se optase por la opción 1 en relación con la Modalidad II, se eliminaría del Reglamento el proyecto de artículo 8 *bis*) y para evitar dudas, no aparecería en ningún lugar.

6. Decisión

47. Proyecto de artículo 8 *bis*) (Decisión del tercero neutral)

“1. Al expirar la etapa del arreglo facilitado, el tercero neutral procederá a comunicar una fecha a las partes para que presenten la documentación definitiva. Esa fecha estará dentro de los diez (10) días de calendario siguientes a la fecha en que haya expirado la etapa del arreglo facilitado.

2. El tercero neutral evaluará la controversia basándose en la información presentada por las partes y pronunciará una decisión. El proveedor de servicios ODR comunicará la decisión a las partes [y la decisión se consignará en la plataforma ODR].

3. Cada una de las partes asumirá la carga de probar todo hecho alegado en su demanda o en su contestación. El tercero neutral estará facultado para invertir la carga de la prueba cuando, en circunstancias excepcionales, así lo exijan los hechos.

4. La decisión no será vinculante para las partes. No obstante, se alienta a las partes a cumplir lo dispuesto en la decisión y el proveedor de servicios ODR podrá introducir el uso de sellos de confianza u otros métodos para indicar el cumplimiento de las decisiones.”

Observaciones generales

48. El proyecto de artículo 8 *bis*) se aplicaría únicamente si el Grupo de Trabajo decidiese mantener en el párrafo 2) del proyecto de artículo 8 la opción 2 (Modalidad II).

49. Los dos primeros párrafos del proyecto de artículo 8 *bis*) son similares a las disposiciones necesarias para que el tercero neutral pronuncie una decisión de

acuerdo con el proyecto de artículo 9 y en la práctica, el proceso de adopción de decisiones probablemente sería similar, aunque sin un laudo arbitral vinculante y exigible como resultado.

50. Con respecto al proyecto de artículo 8 *bis*) y el proyecto de artículo 9, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si podrían producirse problemas en los procedimientos en los que la misma persona actuase como mediador y como encargado de la adopción de decisiones.

Párrafo 3)

51. Este párrafo se ha trasladado al párrafo 3) del proyecto de artículo 8 *bis*) y también al párrafo 3) del proyecto de artículo 9, habida cuenta de que es aplicable únicamente en la etapa del procedimiento en la que se adoptan decisiones.

52. La segunda oración refleja la propuesta del Grupo de Trabajo de que se incluyese en el reglamento una disposición por la que, en circunstancias excepcionales, se invirtiera la carga de la prueba en las situaciones en que la parte a la que se exigía demostrar un hecho no estuviese en posesión de las pruebas necesarias o no pudiese obtenerlas inmediata o fácilmente (A/CN.9/762, párrafos 66 y 67).

53. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si, en el caso de que cada una de las partes asuma la carga de probar todo hecho alegado en su demanda o en su contestación, por principio el tercero neutral debería tener también la facultad de exigir o pedir que se presentasen los documentos o los datos actualmente incluidos en el párrafo 3) del proyecto de artículo 7 del Reglamento.

7. Arbitraje

54. Proyecto de artículo 9 (Arbitraje)

“1. Al expirar la etapa del arreglo facilitado, el tercero neutral procederá a comunicar una fecha a las partes para que presenten la documentación definitiva. Esa fecha estará dentro de los diez (10) días de calendario siguientes a la fecha en que haya expirado la etapa del arreglo facilitado.

2. El tercero neutral evaluará la controversia basándose en la información presentada por las partes y dictará un laudo. El proveedor de servicios ODR comunicará el laudo a las partes [y el laudo se consignará en la plataforma ODR].

3. Cada una de las partes asumirá la carga de probar todo hecho alegado en su demanda o en su contestación. El tercero neutral estará facultado para invertir la carga de la prueba cuando, en circunstancias excepcionales, así lo exijan los hechos del procedimiento ODR.

4. El laudo deberá figurar por escrito y estar firmado por el tercero neutral, con especificación de la fecha en que fue emitido y el lugar del arbitraje.

[4 bis. El requisito que figura en el párrafo 3) de que:

a) el laudo figure por escrito se dará por cumplido cuando la información que figure en el laudo sea accesible para ulteriores consultas; y

- b) *el laudo esté firmado se dará por cumplido cuando se utilicen datos para identificar al tercero neutral e indicar que aprueba la información que figura en el laudo.]*
5. *El laudo indicará brevemente los motivos en los que se basa.*
6. *El laudo se dictará rápidamente y, en todo caso, dentro de los siete (7) días de calendario (con la posibilidad de una prórroga de otros siete (7) días de calendario) a partir de la fecha en que las partes hayan presentado la documentación definitiva del caso al tercero neutral conforme a lo dispuesto en el párrafo 1). El no haber observado este plazo para dictar el laudo no constituirá motivo para impugnar el laudo.*
- [6 bis. Podrá hacerse público el laudo con el consentimiento de todas las partes o cuando una parte tenga la obligación jurídica de darlo a conocer para proteger o ejercer un derecho, y en la medida en que así sea, o con motivo de un procedimiento legal ante un tribunal u otra autoridad competente.]*
7. *El laudo será definitivo y vinculante para las partes. Las partes deberán cumplir el laudo sin dilación.*
8. *En todos los casos, el tercero neutral decidirá ex æquo et bono con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta todo hecho o circunstancia que sea del caso [, y tendrá en cuenta los usos mercantiles que sean aplicables al caso].”*

Observaciones generales

55. El Grupo de Trabajo convino en su 26º período de sesiones en que se debía mantener el término “laudo” en todo el proyecto de artículo 9 (A/CN.9/762, párrafo 35). Se aclaró además en ese período de sesiones que el término “laudo” se aplicaría únicamente a una etapa de arbitraje del procedimiento ODR (A/CN.9/762, párrafo 30).
56. La Modalidad I del Reglamento concluirá con una etapa de arbitraje que tendrá por resultado un laudo vinculante para todas las partes, salvo por la aplicación de la ley en contrario. De ese modo, la sugerencia del Grupo de Trabajo de que se incluyese en este artículo para su ulterior examen una disposición conforme a la cual el laudo no fuese vinculante para un consumidor cuya participación en el procedimiento ODR se hubiera basado en un acuerdo de arbitraje previo a la controversia invocando el cual se pretendiera privarlo de su derecho a acceder a un tribunal para la solución de la controversia, cuando la ley de la jurisdicción por la que se rigiera el consumidor garantizara ese derecho (A/CN.9/762, párrafos 50 y 52) no se ha incluido (véase A/CN.9/WG.III/WP.119, párrafo 17).
57. Para evitar dudas, en la Modalidad II el procedimiento terminará de acuerdo con el proyecto de artículo 8 (al finalizar la etapa del arreglo facilitado) o con una decisión no vinculante de acuerdo con el proyecto de artículo 8 *bis*), y no se aplicará el proyecto de artículo 9.

Párrafos 1) y 2)

58. El antiguo párrafo 1) se ha reorganizado en dos párrafos (párrafos 1) y 2)) para aclarar la cronología del procedimiento una vez expirada la etapa del arreglo

facilitado, así como las medidas procesales que ha de adoptar el tercero neutral para dictar el laudo. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si el laudo, al igual que el acuerdo de arreglo, debería consignarse en la plataforma ODR.

Párrafo 4)

59. El requisito de que la decisión o el laudo figuren por escrito y estén firmados por el tercero neutral refleja el texto del artículo 31 1) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, así como la decisión del Grupo de Trabajo en su 26º período de sesiones de que en el laudo se indicara la fecha de emisión y el lugar del arbitraje (A/CN.9/762, párrafo 43).

Párrafo 4) bis

60. El Grupo de Trabajo en su 25º período de sesiones propuso que se agregara a la lista de definiciones una definición del término “escrito” que reflejara el texto del artículo 6 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (A/CN.9/744, párrafo 59). En su 26º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que incluyese una definición del término “firma” acorde con los criterios en vigor de la CNUDMI (A/CN.9/762, párrafo 44; véase también A/CN.9/WG.III/WP.119, párrafos 40 y 41).

61. Los requisitos de que el laudo figure por escrito y esté firmado se han insertado constituyendo un nuevo párrafo 4) *bis* y son un reflejo, respectivamente, de los artículos 6 y 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico. También se recurrió a la definición de “firma electrónica” de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas de 2001.

Párrafo 5)

62. El Grupo de Trabajo expresó un amplio consenso en su 26º período de sesiones respecto de que debía incluirse en este artículo una formulación que exigiese una breve descripción de los motivos de la decisión del tercero neutral (A/CN.9/762, párrafo 38).

Párrafo 6)

63. El párrafo 6) (antiguo párrafo 1)) se ha trasladado para aclarar la cronología del procedimiento en la etapa del arbitraje. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar su acuerdo de permitir una prórroga de 7 días de calendario en relación con el plazo en que el tercero neutral puede dictar su laudo (A/CN.9/762, párrafo 37).

64. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la posibilidad de que el tercero neutral no emita una decisión en el plazo previsto en el párrafo 6) (A/CN.9/739, párrafo 133) y además, si sería conveniente o posible imponer sanciones basadas en la reputación a las partes en un procedimiento ODR que no cumplan sus obligaciones (A/CN.9/739, párrafo 136).

Párrafo 6) bis

65. El Grupo de Trabajo tal vez recuerde su decisión de seguir examinando si los laudos deberían hacerse públicos y el mandato que dio a la Secretaría a ese respecto

para que insertara entre corchetes una disposición que reflejara el contenido del artículo 34 5) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (A/CN.9/762).

Párrafo 7)

66. En su 26º período de sesiones el Grupo de Trabajo convino en suprimir los corchetes de este párrafo (A/CN.9/762, párrafo 52).

Párrafo 8)

67. El requisito de que el tercero neutral decida “*ex aequo et bono*”, o de buena fe y basándose en la equidad, se ha insertado para prever el derecho aplicable en relación con una decisión arbitral. El Grupo de Trabajo tal vez recuerde que en su 26º período de sesiones señaló que la redacción anterior de ese párrafo no se ocupaba adecuada ni completamente de la necesidad de un derecho sustantivo (A/CN.9/762, párrafo 58).

68. Una determinación *ex aequo et bono* incorpora los principios de rapidez, sentido común y equidad que el Grupo de Trabajo ha señalado como fundamentales en un procedimiento ODR (A/CN.9/716, párrafo 101). Ese tipo arbitraje (en el que el tercero neutral puede resolver la controversia basándose en los principios que considera justos, sin tener que referirse a ningún corpus jurídico en particular) no se conoce o se utiliza actualmente en todos los ordenamientos jurídicos. En la Nota explicativa de la Secretaría de la CNUDMI sobre la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 modificada en 2006 (la “Ley Modelo”) se indica que aunque la Ley Modelo se refiere a principios *ex aequo et bono* en el artículo 28 3), no pretende regular esa esfera. La Ley Modelo más bien señala a la atención de las partes la necesidad de incluir aclaraciones al respecto en el acuerdo de arbitraje. De igual modo, en la Ley Modelo se deja claro que en todos los casos en los que la controversia se refiere a un contrato (incluido un arbitraje *ex aequo et bono*) el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. La misma redacción se refleja en el párrafo 8) del presente Reglamento.

69. El principio *ex aequo et bono* aparece también en el artículo 35 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, cuando las partes autorizan a un tribunal arbitral a resolver la controversia basándose en él.

70. El Grupo de Trabajo tal vez desee tener en cuenta que en algunos Estados es necesario un acuerdo expreso entre las partes para someter la controversia a arbitraje sobre la base de principios *ex aequo et bono*. Por ello, tal vez fuese conveniente indicar en la cláusula sobre la solución de controversias entre las partes cual sería la ley aplicable (véase A/CN.9/WG.III/119, párrafo 30). Sin embargo, como se indicó más arriba en el comentario y como se enuncia en el proyecto de artículo 1 del propio Reglamento, este es de naturaleza contractual y nada de lo dispuesto en él anula lo dispuesto en la legislación nacional, inclusive en relación con las esferas del derecho aplicable. Tampoco trataría de regular esa esfera el Reglamento (cf. la Ley Modelo).

71. [Proyecto de artículo 9 bis) Rectificación del laudo

“Dentro de los [cinco (5)] días de calendario siguientes a la recepción del laudo, toda parte podrá, previo aviso a la otra parte, solicitar al tercero

neutral que rectifique en su laudo todo error de cómputo, tipográfico o de copia [, o todo error u omisión de índole similar]. Si el tercero neutral considera que esa solicitud está justificada, efectuará la rectificación [, incluida una breve justificación de la misma,] dentro de los [dos (2)] días de calendario siguientes a la recepción de la solicitud. La rectificación [se consignará en la plataforma ODR y] formará parte del laudo. [Dentro de los [cinco (5)] días de calendario siguientes a la comunicación del laudo, el tercero neutral podrá efectuar dichas correcciones por iniciativa propia.]]

Observaciones

72. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar que en su 26º período de sesiones solicitó que se añadiese un nuevo proyecto de artículo 9 *bis*) que dispusiera la rectificación de los laudos (A/CN.9/762, párrafos 55 y 56). Una sugerencia similar de que se incorporase una disposición sobre la interpretación del laudo no se ha incluido en el presente proyecto, en aras de hacerlo más simple.

73. Proyecto de artículo 9 *ter*) Mecanismo de revisión interna

“[1. Cada una de las partes podrá pedir la anulación del laudo en un plazo de diez (10) días de calendario desde la comunicación del laudo, solicitándolo al proveedor de servicios ODR por conducto de la plataforma ODR y por los motivos siguientes: a) el lugar del arbitraje perjudicó injustamente a la parte; o b) el laudo se ha apartado gravemente de una norma fundamental de procedimiento y ha menoscabado el derecho de la parte a que se respeten las garantías procesales.]

[2. El proveedor de servicios ODR nombrará a un tercero neutral i) ajeno al procedimiento ODR objeto de la petición y ii) de una lista de terceros neutrales cualificados que deberá llevar el proveedor de servicios ODR [o que provenga de otras instituciones arbitrales], para que evalúe la petición en un plazo de cinco (5) días de calendario. Una vez nombrado el tercero neutral, el proveedor de servicios ODR deberá notificar ese nombramiento a las partes.

[3. Ese tercero neutral emitirá una decisión definitiva sobre la petición de anulación dentro de un plazo de siete (7) días de calendario de su nombramiento. Si el laudo es anulado, el procedimiento ODR se someterá, a petición de cualquiera de las partes, a un nuevo tercero neutral nombrado de acuerdo con el artículo 6.]”

Observaciones generales

74. El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si el Reglamento debería permitir a los proveedores de servicios ODR crear un mecanismo secundario de revisión procesal, u obligarles a ello, en circunstancias limitadas. Ese mecanismo de revisión, de carácter estrictamente procesal y no basado en el fondo del asunto, proporcionaría un proceso ODR más autónomo y permitiría la revisión en línea de cualquier vicio de procedimiento posterior al laudo. Un mecanismo de revisión de ese tipo podría funcionar de modo que la parte, una vez dictado el laudo arbitral, pudiese recurrir ante el mecanismo de revisión para que lo anulase si considerara que ha recibido menos protección procesal que en su propia jurisdicción. Una revisión interna no entraría a examinar el fondo del asunto.

75. Por una parte, un mecanismo de ese tipo podría hacer menos importante el lugar del procedimiento y hacer menos necesario recurrir a los tribunales en lugar del arbitraje, lo que podría ser poco práctico; por otra, un mecanismo de ese tipo tal vez no sea práctico para un proveedor de servicios ODR que resuelva un número elevado de controversias al año.

76. Esa disposición solo se aplicaría en la etapa del arbitraje en la que el laudo se dicte con arreglo al proyecto de artículo 9.

77. Proyecto de artículo 10 (Lugar de las actuaciones)

“[El proveedor de servicios ODR escogerá el lugar de las actuaciones de la lista enunciada en el apéndice [de la Modalidad I] del presente Reglamento.]”

Observaciones

78. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar su decisión de que el Reglamento se ocupase de cómo determinar el lugar del arbitraje (A/CN.9/762, párrafo 41). El proyecto de artículo 10 solo es aplicable al procedimiento llevado a cabo conforme a la Modalidad I, ya que la sede de las actuaciones carecería de importancia en cualquier etapa que no incluya el arbitraje.

79. Los arbitrajes, aunque sean en línea, deben tener una sede o lugar de arbitraje, a fin de establecer el derecho procesal que les es aplicable y evitar la incertidumbre y el debate sobre la validez jurídica del laudo. La sede ha de ser también un país signatario de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (la “Convención de Nueva York”) para que esa Convención tenga más posibilidades de ser aplicable al laudo. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la posibilidad de incorporar una lista larga o corta de países que se incluiría en el apéndice de la Modalidad I, basada en los países signatarios de la Convención de Nueva York y la Convención sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales y también en si un país ha aprobado legislación basada en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.

80. El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar cómo se debe determinar la sede, es decir, si se debe permitir al proveedor de servicios ODR que escoja la sede de una lista predeterminada, como se dispone actualmente en el proyecto de artículo 10, con lo que se promovería la flexibilidad y se permitiría a los proveedores regionales que escogiesen una sede de su región, o si serían preferibles opciones alternativas, como por ejemplo una única sede para todos los procedimientos ODR, análoga al Court of Arbitration for Sport, que especifica que el lugar de todos los arbitrajes llevados a cabo con arreglo a su reglamento será Suiza. Si el Grupo de Trabajo considerase conveniente una única “sede mundial” como esta, dicha sede se podría especificar en el proyecto de artículo 10 y en la cláusula sobre solución de controversias entre las partes, y por ello podría generar mayor certidumbre.

8. Disposiciones generales

81. Proyecto de artículo 11 (Proveedor de servicios ODR)

“[Se especificará en la cláusula sobre solución de controversias el proveedor de servicios ODR.]”

Observaciones

82. Se ha incorporado esta disposición a fin de que el Reglamento incluya un modo de garantizar que se especifique en la cláusula compromisoria el proveedor de servicios ODR que utilizará el vendedor. Esa especificación es necesaria para proporcionar la máxima transparencia, certidumbre y capacidad de elección al comprador y además para garantizar que pueda tener lugar el procedimiento ODR, dado que en el Reglamento no se prevé ningún procedimiento “*ad hoc*” (véase también el párrafo 39 del documento A/CN.9/WG.III/WP.119).

83. El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar qué ocurrirá cuando en la cláusula sobre solución de controversias no se especifique el proveedor de servicios ODR y en concreto, cómo se escogerá el proveedor en ese caso.

84. **Proyecto de artículo 12 (Idioma de las actuaciones)**

“[1. Con sujeción a cualquier acuerdo entre las partes, el tercero neutral determinará rápidamente después de su nombramiento el idioma o idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones [, teniendo en cuenta los derechos que asisten a las partes en el procedimiento en virtud del artículo [x]].

2. Todas las comunicaciones, salvo las contempladas en el párrafo 3) infra, se presentarán en el idioma de las actuaciones (acordado o determinado de acuerdo con el presente artículo) y cuando haya más de un idioma de las actuaciones, en uno de ellos.

3. Todo documento adjunto a las comunicaciones y todo documento complementario o probatorio podrá presentarse en el curso del procedimiento de ODR en su idioma original, siempre que no se haya impugnado su contenido.

4. Si una reclamación se basa en un documento o prueba cuyo contenido se haya impugnado, el tercero neutral podrá exigir a la parte interesada que presente ese documento o prueba acompañados de una traducción [a un idioma que la otra parte comprenda] [al otro idioma de las actuaciones] [o si no, al idioma que incluyó en su aviso o contestación la otra parte como el idioma que prefería]].”

Observaciones generales

85. En su 26º período de sesiones, el Grupo de Trabajo propuso una nueva redacción del proyecto de artículo 12 (Idioma de las actuaciones) (A/CN.9/762, párrafos 75 a 81). Se ha incluido esa redacción, junto con alguna variante para mantener su sentido pero hacerla más concisa o ajustarla más a la redacción de otros textos de la CNUDMI.

86. En el 26º período de sesiones del Grupo de Trabajo, así como en su 25º período de sesiones, se propuso que se insertara un párrafo independiente del siguiente tenor (A/CN.9/762, párrafo 75; A/CN.9/739, párrafo 143): “Todo proveedor de servicios ODR que tenga trato con partes que usen distintos idiomas se cerciorará de que su sistema, su Reglamento y los terceros neutrales tengan en cuenta esas diferencias y establecerá mecanismos para atender a las necesidades de las partes al respecto”. El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si sería mejor ubicar esa disposición en las directrices y requisitos mínimos para los proveedores de

servicios ODR; en concreto, el Grupo de Trabajo ha reconocido anteriormente que el Reglamento no puede imponer obligaciones a los proveedores de servicios ODR (A/CN.9/744, párrafo 78), y a ese respecto, tal vez desee examinar hasta qué punto puede o debe decidir el Reglamento los sistemas que aplique y use un proveedor de servicios ODR.

Párrafo 1)

87. La redacción propuesta por el Grupo de Trabajo en su 26º período de sesiones en relación con párrafo 1) era la siguiente: “El procedimiento ODR será sustanciado en el idioma o los idiomas convenidos por las partes en el momento de la apertura de ese procedimiento.” Dado que el Grupo de Trabajo indicó que el idioma se debe acordar al comienzo de las actuaciones, se ha modificado ligeramente la redacción del apartado g) del párrafo 4) del artículo 4A y del apartado f) del párrafo 3) del artículo 4B, para permitir ese acuerdo. Especialmente, cabe señalar que en la actualidad, esas disposiciones permiten a cada parte especificar un único idioma preferido; de ese modo, las partes pueden convenir en un idioma o proponer en total dos idiomas diferentes, en cuyo caso el tercero neutral habrá de determinar si ambos idiomas serán los “idiomas de las actuaciones”. El Grupo de Trabajo tal vez desee también tener en cuenta que se puede especificar en el propio contrato entre las partes el idioma de las actuaciones.

88. La redacción propuesta por el Grupo de Trabajo en su 26º período de sesiones en relación con el párrafo 2) era la siguiente: “Si las partes no se ponen de acuerdo respecto del idioma de las actuaciones, el tercero neutral deberá determinar el idioma o los idiomas que se utilizarán, teniendo en cuenta los derechos que asisten a las partes en el procedimiento en virtud del artículo [x]”.

89. En aras de la claridad y la brevedad, esos dos párrafos propuestos por el Grupo de Trabajo que figuran en los párrafos 86 y 87 *supra* se han reformulado y refundido y ahora constituyen el párrafo 1) del proyecto de artículo 12. Además, ahora el párrafo 1) se ajusta más estrechamente a la redacción del artículo 19 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

90. Se ha mantenido entre corchetes la referencia que propuso el Grupo de Trabajo en su 26º período de sesiones a los derechos que asisten a las partes en el procedimiento. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar su debate sobre si bastaría con una referencia a los poderes otorgados al tercero neutral para cumplir un proceso justo y eficiente para resolver el litigio, enunciados actualmente en el párrafo 1) *bis* del proyecto de artículo 7, o si sería necesaria una referencia a un artículo aún no determinado (A/CN.9/762, párrafo 76).

Párrafo 2)

91. El Grupo de Trabajo tal vez desee analizar si este párrafo tendría mejor acomodo en el proyecto de artículo 3 (Comunicaciones).

Párrafo 4)

92. El Grupo de Trabajo tal vez desee determinar si la traducción, en caso de ser necesaria, se ha de hacer al idioma “que la otra parte comprenda” o al otro idioma de las actuaciones, de haberlo, y si no, al idioma que indicó la otra parte como su

idioma preferido con arreglo a lo dispuesto en el proyecto de artículo 4A (Aviso) o 4B (Contestación).

93. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar que varias delegaciones habían expresado preocupación en relación con un posible requisito de traducir los documentos, dado que ese requisito impondría a los consumidores unos costos desproporcionados (A/CN.9/762, párrafo 80).

94. El Grupo de Trabajo tal vez desee tener en cuenta también que en los casos en que el tercero neutral necesite examinar la documentación de apoyo presentada por las partes, el proveedor de servicios ODR tal vez deba nombrar a un tercero neutral que entienda el idioma o los idiomas pertinentes.

95. **Proyecto de artículo 13 (Representación)**

“Toda parte podrá hacerse representar o asesorar por una o más personas seleccionadas por ella. Los nombres y las direcciones electrónicas de la persona o las personas seleccionadas [y el poder para actuar en nombre de la parte interesada] deberán ser comunicados a la otra parte por conducto del proveedor de servicios ODR.”

96. **Proyecto de artículo 14 (Exclusión de responsabilidad)**

“[Salvo en caso de falta intencional, en la máxima medida que permita la ley aplicable, las partes renuncian a cualquier reclamación contra el proveedor de servicios ODR y el tercero neutral por actos u omisiones relacionados con el procedimiento ODR en virtud del Reglamento.]”

Observaciones

97. El proyecto de artículo 14 trata de la cuestión de la exclusión de responsabilidad de toda persona que intervenga en el procedimiento ODR. Se ha redactado de nuevo para reflejar el artículo 16 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

98. **Proyecto de artículo 15 (Costas)**

“[El tercero neutral no emitirá [decisión alguna] [laudo alguno] acerca de las costas y cada parte habrá de sufragar sus propios gastos.]”

Observaciones

99. El término “costas” se refiere a una orden emitida por un tercero neutral a efectos de que una parte (en general, la parte perdedora) pague dinero a otra (en general, la parte ganadora) para compensar los gastos de la parte ganadora ocasionados por el caso.

**E. Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea
en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico:
plazos, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de
Controversias en Línea en su 27º período de sesiones**

(A/CN.9/WG.III/WP.120)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-3
II. Solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: plazos	4-24
A. Plazos comunes a las modalidades I y II	4-14
B. Plazos aplicables únicamente a la modalidad I	15-21
C. Plazos aplicables únicamente a la modalidad II	22-24

I. Introducción

1. En su 26º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que, en su 27º período de sesiones, le proporcionara una lista de los plazos previstos en el proyecto de reglamento para la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico (“el Reglamento”). El Grupo sugirió que esta se examinara, conjuntamente con una disposición general relativa a la modificación o prórroga de esos plazos con el consentimiento de las partes, en uno de sus futuros períodos de sesiones (A/CN.9/762, párr. 57).

2. En el documento A/CN.9/WG.III/WP.119 y su adición se establecía un proyecto de reglamento para la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico y se preveían dos posibles modalidades, que constituirían conjuntos de artículos separados y autónomos; una de ellas terminaría en la etapa del arbitraje (la “modalidad I”) y la otra sin recurso al arbitraje (la “modalidad II”), ya fuese (conforme decidiera el Grupo de Trabajo) al concluir la etapa del arreglo facilitado o, si no se hubiera alcanzado un arreglo, con una decisión no vinculante de un tercero neutral, ejecutable por conducto de mecanismos privados como los sellos de confianza (véase A/CN.9/WG.III/WP.119, párrs. 15 a 20). Por consiguiente, en la presente nota se indican los plazos comunes a ambas modalidades y los plazos que se preverían en las normas del reglamento correspondientes a las actuaciones realizadas conforme a la modalidad I o la modalidad II.

3. En los casos en que no se ha acordado definitivamente el plazo en una disposición pertinente y se ha dejado el texto entre corchetes para que lo examine el Grupo de Trabajo en el proyecto de reglamento, esos corchetes se mantienen en la presente nota.

II. Solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: plazos

A. Plazos comunes a las modalidades I y II

Observaciones generales

4. En varias disposiciones se requiere que el proveedor de servicios ODR o el tercero neutral determinen con rapidez las comunicaciones enviadas mediante la plataforma ODR o que se notifiquen dichas comunicaciones prontamente a las partes o al tercero neutral. A modo de ejemplos no exhaustivos:

- i) El proveedor de servicios ODR comunicará rápidamente los acuses de recibo de comunicaciones electrónicas entre las partes y el tercero neutral a todas las partes [y al tercero neutral] enviándolos a sus respectivas direcciones electrónicas designadas (proyecto de artículo 3 6)).
- ii) El proveedor de servicios ODR notificará rápidamente a todas las partes y al tercero neutral toda comunicación electrónica recibida en la plataforma ODR (proyecto de artículo 3 7)).
- iii) Con sujeción a cualquier acuerdo entre las partes, el tercero neutral determinará rápidamente después de su nombramiento el idioma o idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones (proyecto de artículo 12 1)).

5. En aras de la concisión, en la presente nota no se reproducen todas esas disposiciones. De igual modo, se omiten las disposiciones que pudiesen referirse al momento de proceder (por ejemplo, la obligación de que en el momento de la operación cada parte proporcione su información de contacto por vía electrónica, prevista en el proyecto de artículo 3 2)), pero para la cual no se fija un plazo determinado.

Apertura del procedimiento ODR (Contestación)

6. El demandado comunicará al proveedor de servicios ODR su contestación al aviso ... dentro de los siete (7) días de calendario siguientes a la fecha de recepción del aviso (proyecto de artículo 4B 1)).

7. La contrademanda del demandado deberá comunicarse a más tardar [siete (7)] días de calendario después de que el aviso de la demanda del demandante haya sido comunicado al proveedor de servicios ODR (proyecto de artículo 4B 2), opciones 1 y 2).

Negociación y nombramiento de un tercero neutral

8. [Tras la comunicación de la contestación ... al proveedor de servicios ODR, las partes tratarán de arreglar su controversia mediante negociaciones directas...] (proyecto de artículo 5 1)).

9. Si el demandado no comunica al proveedor de servicios ODR su contestación al aviso ... en un plazo de siete (7) días de calendario, ... el procedimiento ODR pasará automáticamente a la etapa del arreglo facilitado, en cuyo momento el

proveedor de servicios ODR deberá proceder rápidamente al nombramiento de un tercero neutral con arreglo a lo previsto en el artículo 6 (proyecto de artículo 5 2)).

10. Si las partes no han arreglado su controversia mediante la negociación en el plazo de diez (10) días de calendario el procedimiento ODR pasará automáticamente a la etapa del arreglo facilitado, en cuyo momento el proveedor de servicios ODR deberá proceder rápidamente al nombramiento de un tercero neutral con arreglo a lo previsto en el artículo 6 (proyecto de artículo 5 3)).

11. Las partes podrán convenir en prorrogar una vez el plazo para [presentar la contestación] [llegar a un arreglo]. No obstante, dicha prórroga no podrá exceder de diez (10) días de calendario (proyecto de artículo 5 4)).

Impugnación del nombramiento del tercero neutral

12. Toda parte podrá impugnar el nombramiento del tercero neutral dentro de los [dos (2)] días de calendario siguientes [i)] a la notificación del nombramiento ... [; o ii) al haberse enterado de un hecho o asunto que pueda suscitar dudas fundadas sobre la imparcialidad o la independencia del tercero neutral ... en cualquier momento en el curso del procedimiento ODR] (proyecto de artículo 6 5)).

13. [Cuando una parte se oponga al nombramiento de un tercero neutral con arreglo a lo dispuesto en el proyecto de artículo 6 5) ii), [el proveedor de servicios ODR] determinará en un plazo de [tres (3)] días de calendario si ese tercero neutral habrá de ser sustituido] (proyecto de artículo 6 5) *bis*).

14. [Cada una de las partes podrá expresar sus reparos, en el plazo de tres (3) días de calendario contados a partir del nombramiento definitivo del tercero neutral, a que el proveedor de servicios ODR suministre a ese tercero neutral información generada durante la etapa de negociación. Tras cumplirse ese plazo de tres días, y si no hay objeciones, el proveedor de servicios ODR transmitirá al tercero neutral toda la información existente en la plataforma ODR] (proyecto de artículo 6 6)).

B. Plazos aplicables únicamente a la modalidad I

Expiración de la etapa del arreglo facilitado

15. Cuando las partes no hayan arreglado su controversia mediante el arreglo facilitado [en el plazo de diez (10) días de calendario a partir del nombramiento del tercero neutral] (la “expiración de la etapa del arreglo facilitado”), el procedimiento ODR pasará automáticamente a la etapa del arbitraje (proyecto de artículo 8 2), modalidad I).

Arbitraje

16. Al expirar la etapa del arreglo facilitado, el tercero neutral procederá a comunicar una fecha a las partes para que presenten la documentación definitiva. Esa fecha estará dentro de los diez (10) días de calendario siguientes a la fecha en que haya expirado la etapa del arreglo facilitado (proyecto de artículo 9 1)).

17. El tercero neutral ... dictará un laudo (proyecto de artículo 9 2)). El laudo se dictará rápidamente y, en todo caso, dentro de los siete (7) días de calendario (con la posibilidad de una prórroga de otros siete (7) días de calendario) a partir de la fecha

en que las partes hayan presentado la documentación definitiva (proyecto de artículo 9 6)).

[Rectificación del laudo

18. Dentro de los [cinco (5)] días de calendario siguientes a la recepción del laudo, toda parte podrá, previo aviso a la otra parte, solicitar al tercero neutral que rectifique en su laudo todo error de cómputo, tipográfico o de copia [, o todo error u omisión de índole similar]. Si el tercero neutral considera que esa solicitud está justificada, efectuará la rectificación [, incluida una breve justificación de la misma,] dentro de los [dos (2)] días de calendario siguientes a la recepción de la solicitud. La rectificación [se consignará en la plataforma ODR y] formará parte del laudo. [Dentro de los [cinco (5)] días de calendario siguientes a la comunicación del laudo, el tercero neutral podrá efectuar dichas correcciones por iniciativa propia.] (proyecto de artículo 9 *bis*)).]

[Mecanismo de revisión interna

19. Cada una de las partes podrá pedir la anulación del laudo en un plazo de diez (10) días de calendario desde la comunicación del laudo ... (proyecto de artículo 9 *ter*) 1)).

20. El proveedor de servicios ODR nombrará a un tercero neutral ... para que evalúe la petición en un plazo de cinco (5) días de calendario (proyecto de artículo 9 *ter*) 2)).

21. Ese tercero neutral emitirá una decisión definitiva sobre la petición de anulación dentro de un plazo de siete (7) días de calendario de su nombramiento. Si el laudo es anulado, el procedimiento ODR se someterá, a petición de cualquiera de las partes, a un nuevo tercero neutral nombrado de acuerdo con el artículo 6.]

C. Plazos aplicables únicamente a la modalidad II

Expiración de la etapa del arreglo facilitado

22. Cuando las partes no hayan arreglado su controversia mediante el arreglo facilitado [en el plazo de [diez (10)] días de calendario a partir del nombramiento del tercero neutral], el procedimiento ODR se dará automáticamente por terminado (proyecto de artículo 8 2), opción 1, modalidad II).

23. Cuando las partes no hayan arreglado su controversia mediante el arreglo facilitado [en el plazo de [diez (10)] días de calendario a partir del nombramiento del tercero neutral] (la “expiración de la etapa del arreglo facilitado”), el procedimiento ODR pasará automáticamente a la etapa definitiva de las actuaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 *bis*) (proyecto de artículo 8 2), opción 2, modalidad II).

Decisión del tercero neutral (proyecto de artículo 8, opción 2, modalidad II)

24. Al expirar la etapa del arreglo facilitado, el tercero neutral procederá a comunicar una fecha a las partes para que presenten la documentación definitiva. Esa fecha estará dentro de los diez (10) días de calendario siguientes a la fecha en que haya expirado la etapa del arreglo facilitado (proyecto de artículo 8 *bis* 1)).

F. Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento — Propuesta de la delegación de observadores de la Unión Europea, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 27º período de sesiones

(A/CN.9/WG.III/WP.121)

[Original: inglés]

Índice

Párrafos

I. Introducción.....	1
II. Propuesta de la delegación de observadores de la Unión Europea	

I. Introducción

1. En el curso del 27º período de sesiones del Grupo de Trabajo III (Solución de Controversias en Línea), la delegación de observadores de la Unión Europea presentó a la Secretaría el siguiente texto, que se reproduce a continuación en la forma en que se recibió.

II. Propuesta de la delegación de observadores de la Unión Europea

A. Deliberaciones del Grupo de Trabajo III: situación actual

1. Mandato de la CNUDMI

En 2010 la CNUDMI encomendó a su Grupo de Trabajo III la elaboración de una norma jurídica en materia de solución de controversias en línea (ODR) relativa a las operaciones transfronterizas de comercio electrónico, particularmente las operaciones entre empresas y entre empresas y consumidores¹. Desde entonces, el Grupo de Trabajo III ha examinado proyectos de reglamento de un proceso de ODR en relación con las operaciones transfronterizas de comercio electrónico de poco valor y gran volumen (“el Reglamento”). Convino en que el Reglamento adoptaría la forma de normas contractuales genéricas pactadas por los comerciantes que operan por Internet y sus clientes en el contexto de una operación de comercio electrónico². La idea es que el hecho de dar la posibilidad de solucionar las controversias a que haya dado lugar una operación de comercio electrónico mediante un procedimiento de ODR que cumpla una norma internacionalmente

¹ Informe del 43º período de sesiones de la Comisión (2010), A/65/17, párr. 257, confirmado en el informe de su 44º período de sesiones (2011), A/66/17, párr. 218, y el informe de su 45º período de sesiones (2012), A/67/17, párr. 79.

² Véase el informe del 25º período de sesiones del Grupo de Trabajo III (Nueva York, mayo de 2012), A/CN.9/744, párr. 16.

reconocida (es decir, el “Reglamento de la CNUDMI para la solución de controversias en línea”), reforzaría la confianza de los compradores y los vendedores en la compraventa en línea y transfronteriza.

El amplio alcance de la iniciativa (que comprende no solo las operaciones entre empresas, sino también las operaciones entre empresas y consumidores) refleja dos características esenciales de las operaciones de comercio electrónico de poco valor y gran volumen:

En primer lugar, en ellas suelen participar consumidores. Incluso cabe afirmar que esas operaciones son un paradigma en materia de operaciones con los consumidores;

En segundo lugar, las operaciones realizadas en línea se diferencian de las realizadas por otras vías. Si bien en esas otras el vendedor suele saber si se trata de una operación entre empresas o de una operación entre una empresa y un consumidor, en las operaciones realizadas en línea el vendedor se limita a consignar sus condiciones en su sitio web y el comprador las acepta tildando la casilla correspondiente, independientemente de la categoría en que esté comprendido (empresa o consumidor)³.

En ese contexto, la CNUDMI ha pedido a su Grupo de Trabajo III que tenga especialmente en cuenta la legislación orientada a proteger al consumidor y, en general, que estudie concretamente los efectos que sus deliberaciones puedan tener en la protección de los consumidores⁴. Ese mandato obedece también a otro hecho fundamental: en los países en desarrollo y los países desarrollados los consumidores son una fuerza motriz esencial de la economía mundial⁵, especialmente en lo que respecta a aprovechar el potencial del comercio electrónico. Para cumplir el objetivo de inspirar confianza a esos agentes fundamentales de la venta en línea y transfronteriza, el Reglamento ha de estar a la altura de sus expectativas.

2. Formulación del Reglamento: ¿el arbitraje como modelo para formular una norma mundial en materia de ODR en relación con las operaciones de comercio electrónico de poco valor y gran volumen?

Los procesos de ODR y los mecanismos para garantizar el cumplimiento de sus resultados pueden formularse de muchas maneras. Hasta su 26º período de sesiones (Viena, noviembre de 2012), el Grupo de Trabajo III deliberó intensamente sobre la posibilidad de que el Reglamento desembocara en una etapa de arbitraje. En ese contexto, también se estudió si podía establecerse un procedimiento de arbitraje, en la inteligencia de que, en todos los casos, se concertarían acuerdos de arbitraje pertinentes en el momento de la operación, es decir, antes de surgir controversia alguna (“acuerdos de arbitraje previos a una controversia”), que fueran vinculantes para ambas partes.

³ Eso significa que en esas operaciones, aunque se estipule que las condiciones solo son aplicables cuando el comprador sea una empresa (una operación entre empresas), de hecho esas condiciones también se aceptarían aunque el comprador fuera un consumidor, a no ser que se dispusiera de un mecanismo que permitiera que en el sitio web del vendedor se determinara la clase de comprador que es (una empresa o un consumidor).

⁴ Véase el informe del 44º período de sesiones de la Comisión (2011), A/66/17, párr. 218.

⁵ En la Unión Europea, por ejemplo, los gastos de los consumidores representan el 56% del PIB.

Las deliberaciones centradas en el posible modelo del arbitraje resultaron controvertidas por dos motivos:

En primer lugar, formular el Reglamento tomando únicamente como base el modelo del arbitraje no habría reflejado la realidad de los procesos de ODR en todo el mundo. De hecho, muchos procesos de ODR satisfactorios hoy en día no están basados en el modelo del arbitraje⁶. A diferencia de los procedimientos de arbitraje, esos procesos no arrojan resultados que sean vinculantes para el comprador y el cumplimiento de los resultados queda garantizado mediante mecanismos de ejecución privados. Además, los procedimientos de arbitraje son engorrosos desde el punto de vista procesal y cabe dudar del valor añadido del arbitraje en línea en lo que respecta a la ejecución transfronteriza de laudos arbitrales en el marco de un proceso de esa índole. No queda claro que los laudos arbitrales dictados en el marco de esos procesos puedan ejecutarse con arreglo a la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras⁷. Aun suponiendo que así fuera, no es muy realista pensar que los laudos arbitrales dictados en el contexto de operaciones de poco valor y gran volumen podrían ejecutarse a escala transfronteriza con arreglo a la Convención de Nueva York de 1958, especialmente cuando el demandante fuera un consumidor o una pequeña o mediana empresa. En ese contexto, cabe señalar que el hecho de que se adjudique un laudo arbitral no da lugar automáticamente a la posibilidad de que el demandante lo haga valer contra la otra parte. Para dar curso a un laudo arbitral, su ejecutante (el demandante) ha de acudir al tribunal local competente del lugar en que el ejecutado (el demandado) tenga sus bienes y solicitar que el laudo se declare ejecutable. Dicho de otro modo, para poder ejecutarlo el demandante debe recurrir al sistema judicial. Eso resulta problemático cuando no funciona bien el sistema judicial del lugar en que reside el acusado o en que se encuentran sus bienes⁸. Además, solicitar a un tribunal que declare ejecutable un laudo arbitral es costoso, más aún cuando el ejecutado (el demandado) se encuentra en otro país. Sobre todo en un contexto como el previsto en el Reglamento, es decir, en el de las operaciones transfronterizas de poco valor y gran volumen, es muy probable que el costo de ejecutar un laudo arbitral sea muy superior a la suma adjudicada. Así pues, sería desproporcionado que los ejecutantes (los demandantes) procuraran ejecutar sus laudos, especialmente si se trata de consumidores o pequeñas o medianas empresas.

En segundo lugar, en cuanto a las operaciones entre empresas y consumidores, los Estados están divididos en lo que respecta a la norma jurídica concerniente al efecto que tienen en los consumidores los acuerdos de arbitraje previos a una controversia. Existen dos normas divergentes:

⁶ Véase Vikki Rogers, *Managing Disputes in the Global Market Place. Reviewing the Progress of UNCITRAL's Working Group III on ODR*, que se publicará en el número de primavera de "Dispute Resolution Magazine" (el borrador se puede consultar en: <http://blogs.law.stanford.edu/codr2013/files/2013/03/Dispute-Resolution-Magazine-Final-Draft.pdf> [consultado el 6 de mayo de 2013]).

⁷ Véase la nota de antecedentes A/CN.9/WG.III/WP.110, en que la Secretaría de la CNUDMI expone varias cuestiones por resolver al respecto.

⁸ La iniciativa de ODR de la CNUDMI también tiene por objeto contribuir al desarrollo del comercio electrónico en los países en que el sistema judicial no funciona bien. Si la iniciativa se formula de tal manera que los ejecutantes de los laudos (los demandantes) se vean obligados a recurrir a esos sistemas judiciales, las partes de esos países saldrán perdiendo.

En un grupo de Estados (los “Estados del Grupo I”), los acuerdos de arbitraje previos a una controversia se consideran vinculantes para todas las partes, independientemente de si una de ellas es un consumidor o no⁹.

En otro grupo de Estados (los “Estados del Grupo II”), los acuerdos de arbitraje previos a una controversia se consideran no vinculantes para el consumidor o pueden ser invalidados por este. No obstante, los acuerdos de arbitraje concertados con los consumidores se consideran vinculantes para las dos partes (incluido el consumidor) cuando se conciertan *tras* haber surgido la controversia¹⁰.

3. Resultados del 26º período de sesiones del Grupo de Trabajo III (Viena, noviembre de 2012)

En vista de que la presencia de una vía arbitral en el Reglamento era importante para algunos “Estados del Grupo I” y de que, como subrayaron los “Estados del Grupo II” -si el Reglamento tuviera que contener una vía arbitral- en relación con los acuerdos de arbitraje concertados con los consumidores antes de que surja una controversia, el Reglamento, entendido como norma *mundial* para un proceso de ODR, no podía formularse tomando como modelo las normas de un solo grupo de Estados, el Grupo de Trabajo III llegó a la siguiente solución de avenencia al término de su 26º período de sesiones:

1. En el Reglamento debería adoptarse un “enfoque con dos modalidades”, lo que significa que este debería formularse con flexibilidad con objeto de ofrecer una vía de procedimiento que desemboque en el arbitraje (la “vía arbitral”) y otra que no lo haga (la “vía no arbitral”);
2. En cuanto a la vía arbitral, en el Reglamento deberían reflejarse las normas divergentes de los Estados del Grupo I y el Grupo II en relación con los acuerdos de arbitraje concertados con los consumidores antes de que surja una controversia, lo que, en la práctica, significaría que la vía arbitral podría formularse en la inteligencia de que esos acuerdos serían vinculantes siempre y cuando participara en la operación un consumidor de uno de los Estados del Grupo I. Cuando participara un consumidor de uno de los Estados del Grupo II, la vía arbitral tendría que respetar la norma pertinente de los Estados del Grupo II¹¹.

⁹ Entre ellos figuran los Estados Unidos de América y algunos otros Estados. Sin embargo, en lo que concierne a los Estados Unidos, cabe señalar que el 7 de mayo de 2013 se presentó al Senado de ese país un proyecto de “Ley de 2013 sobre imparcialidad en el arbitraje”. En él se propone enmendar el Capítulo 9 del Código de los Estados Unidos, entre otras cosas agregando un nuevo párrafo 402 con arreglo al cual “[...] ningún acuerdo de arbitraje previo a una controversia será válido ni ejecutable si exige el arbitraje de una controversia con [...] un consumidor”. De aprobarse ese proyecto, los Estados Unidos dejarían de ser un Estado del Grupo I para pasar a la categoría de “Estados del Grupo II”.

¹⁰ Entre esos Estados cabe mencionar al Japón, los Estados miembros de la Unión Europea (de conformidad con la nueva Directiva del Parlamento Europeo relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo), jurisdicciones canadienses, varios Estados de América Latina y algunos Estados de África. La norma jurídica de Corea del Sur es semejante a la de los Estados mencionados. De aprobarse la “Ley de 2013 sobre imparcialidad en el arbitraje” (véase la nota anterior), los Estados Unidos se sumarían a ese grupo de Estados.

¹¹ Véase el informe del 26º período de sesiones del Grupo de Trabajo III, A/CN.9/762, párrs. 18, 19 y 22.

B. El fondo de la cuestión: respetar en la “vía arbitral” las normas divergentes con respecto a los acuerdos de arbitraje concertados con los consumidores antes de que surja una controversia

1. Por qué en los documentos de trabajo 119 y 119/Add.1 no se da pleno cumplimiento a los resultados del 26º período de sesiones del Grupo de Trabajo III

En los documentos de trabajo publicados por la Secretaría de la CNUDMI en preparación del 27º período de sesiones del Grupo de Trabajo¹² solo se cumple en parte lo acordado por el Grupo de Trabajo en su 26º período de sesiones:

1. Cabe apreciar que en esos documentos de trabajo se aplica el denominado “enfoque con dos modalidades”;
2. No obstante, con respecto a la denominada “vía arbitral” del Reglamento (que en los documentos de trabajo recibe el nombre de “Modalidad I”), esos documentos no garantizan el respeto de la norma aplicable en los “Estados del Grupo II” en relación con los acuerdos de arbitraje concertados con los consumidores antes de que surja una controversia. En cambio, el texto del proyecto de reglamento que figura en esos documentos de trabajo está redactado exclusivamente en función de la norma de los “Estados del Grupo I”.

El Grupo de Trabajo había acordado que, si en el Reglamento se incluía una etapa de arbitraje, se debería incorporar un mecanismo que respetara también las normas de los Estados del Grupo II con respecto a los acuerdos de arbitraje concertados con los consumidores antes de que surgiera una controversia¹³. Los Estados del Grupo II habían aclarado que eso no debía suponer que se “encaminara automáticamente a los consumidores de esos Estados por la vía arbitral del Reglamento”, en el sentido de que, si el comprador fuera un consumidor de un Estado del Grupo II, el Reglamento debía garantizar que, o bien no pudiera acordarse una vía arbitral al principio, o, en caso de que el consumidor aceptara la vía arbitral del Reglamento (por ejemplo, si el vendedor solo ofreciera la Modalidad I del Reglamento), el proveedor de servicios ODR no pudiera poner en marcha la etapa de arbitraje del proceso, a no ser que el consumidor conviniera en ponerla en marcha *tras* haber surgido la controversia (por ejemplo, “haciendo clic una segunda vez”)¹⁴.

2. Por qué no basta con decir que el Reglamento es de carácter estrictamente contractual: un ejemplo práctico

No basta con decir sin más que el Reglamento va a ser de carácter estrictamente contractual (es decir, que no va a formar parte de una convención ni de una ley modelo) y que, en consecuencia, no podrá escapar a la legislación sobre protección del consumidor vigente en los Estados del Grupo II. Aunque la declaración es

¹² Se trata, en concreto, de los documentos de trabajo A/CN.9/WG.III/WP.119 y A/CN.9/WG.III/WP.119/Add.1.

¹³ Véase el informe del 26º período de sesiones del Grupo de Trabajo III, A/CN.9/762, párrs. 18, segunda oración, y 22.

¹⁴ Véase el informe del 26º período de sesiones del Grupo de Trabajo III, A/CN.9/762, párr. 22.

correcta desde el punto de vista fáctico, esa conclusión no resuelve el problema, como se demuestra en el siguiente ejemplo:

Ejemplo: si un consumidor de un Estado del Grupo II concierta, conforme a lo previsto actualmente en los documentos de trabajo 119 y 119/Add.1, un “acuerdo de vía arbitral” con un comerciante que opera por Internet establecido en un Estado del Grupo I, y ambos convienen en presentar las controversias que surjan a un proveedor de servicios ODR establecido en un Estado del Grupo I, la legislación del Estado en cuestión del Grupo II en materia de protección del consumidor no es aplicable al correspondiente procedimiento ODR. Naturalmente, el Reglamento no afecta a la legislación del Estado en cuestión del Grupo I en materia de protección del consumidor, pero, si esa legislación no se aplica, al consumidor no le sirve de ayuda que la legislación de su país en materia de protección del consumidor no se vea perjudicada por el Reglamento.

En la hipótesis expuesta, el proveedor de servicios ODR puede dictar un laudo arbitral contra el consumidor y ordenarle que pague, por ejemplo, 200 dólares. En ese momento, el vendedor procuraría que se ejecutase el laudo contra el consumidor en el Estado del Grupo II en el que este tuviese residencia, lo cual significaría, en la práctica, que el consumidor recibiría, de su propio tribunal o autoridad de ejecución, un mandamiento judicial en el que se le informaría de que se ha dictado un laudo en su contra por el que está obligado a pagar 200 dólares, suma que deberá abonar a no ser que plantee objeciones ante el tribunal o autoridad de ejecución en un plazo determinado.

La inmensa mayoría de los consumidores (que no son letrados especializados en arbitraje internacional), sintiéndose intimidados, procederían a pagar sin más, ya que no sabrían qué hacer, o por considerar excesivo el costo de contratar los servicios de un letrado especializado (que les diría que, de conformidad con la legislación del Estado del Grupo II pertinente, el acuerdo de arbitraje no es vinculante para ellos y que lo pueden cancelar, con lo cual podrían oponerse al reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral y no tendrían que pagar los 200 dólares).

- En consecuencia, la legislación pertinente en materia de protección del consumidor no se aplicaría en la práctica y, por consiguiente, no protegería a los consumidores en cuestión si hubieran aceptado la “vía arbitral” del Reglamento en su forma actual.
- Como se ha señalado antes¹⁵, la CNUDMI no solo encomendó al Grupo de Trabajo III que tuviera muy presente la necesidad de que prevaleciera la legislación en materia de protección del consumidor. La Comisión también decidió que, en general, en el cumplimiento de su mandato, el Grupo de Trabajo tuviera especialmente en cuenta, además, las repercusiones de sus deliberaciones en lo que respecta a la protección del consumidor. En consecuencia, si se sostiene sin más que el Reglamento es de carácter contractual y que, por esa razón, no puede impedir que prevalezca la legislación en materia de protección del consumidor, no se respeta el mandato de la Comisión de estudiar también las repercusiones prácticas del proyecto de reglamento.

¹⁵ Véase el punto A.1 del presente documento.

- Por último, la hipótesis planteada anteriormente (el consumidor se enfrenta a un laudo arbitral extranjero, se siente intimidado y paga sin poner objeciones al reconocimiento y la ejecución del laudo) tendría, en última instancia, la consecuencia de que los consumidores se abstendrían de comprar por Internet y más allá de sus fronteras nacionales. Así pues, en lugar de inspirar confianza al consumidor en las compras en línea y transfronterizas, el Reglamento disuadiría a los consumidores de aprovechar el potencial del comercio electrónico, lo cual se opondría a las razones expresadas por la CNUDMI para justificar su iniciativa de ODR.
- Por consiguiente, si el Reglamento se formulase conforme a lo establecido actualmente en los documentos de trabajo 119 y 119/Add.1, el Grupo de Trabajo III no estaría cumpliendo su mandato.

C. El desafío: encaminar a los compradores por Internet por “la vía adecuada”

En una situación de normas divergentes en materia de arbitraje, la manera más fácil de avanzar en la formulación de una norma mundial en materia de ODR consistiría en plantear, en consonancia con la actual situación de muchos sistemas de ODR, un proceso que no tomara el arbitraje como modelo.

No obstante, si el Grupo de Trabajo opta por incorporar al Reglamento una vía arbitral, el desafío consistirá en encaminar a los compradores por Internet por “la vía adecuada”. “Encaminar a los compradores por la vía adecuada” significa incorporar en el Reglamento un mecanismo que garantice que, en caso de que el comprador sea un consumidor de un Estado del Grupo II, el proceso de ODR no desembogue en arbitraje, a no ser que el consumidor acepte una vía arbitral tras haber surgido la controversia.

D. Futuras medidas: incluir la tecnología en nuestras deliberaciones

En principio, parece haber dos tipos posibles de futuras medidas:

1. El mecanismo que encamine a los compradores por Internet “por la vía adecuada” podría quedar en manos del proveedor de servicios ODR. En el Reglamento podría figurar una definición de “consumidores”, así como dos anexos en los que se enumerarían los Estados del Grupo I y los del Grupo II, mientras que en los principios que habrán de elaborarse para los proveedores de servicios ODR podría preverse que estos garantizaran que, si la controversia afectara a un consumidor de un Estado del Grupo II, el proceso de ODR no pasaría a la etapa de arbitraje, a no ser que el consumidor diera su consentimiento al respecto tras haber surgido la controversia.
2. En vista de que algunas delegaciones subrayaron la importancia de que en el momento de la operación quedara claro si se había acordado un proceso de ODR que desembocara en arbitraje, tal vez esas delegaciones no consideren que la mencionada solución sea una futura medida válida. En consecuencia, el mecanismo para encaminar a los compradores por la vía adecuada tendría que actuar en el momento de la operación, es decir, cuando las partes pacten la

cláusula de ODR. En vista de que esa cláusula se ofrece en el sitio web del comerciante y se acepta cuando el comprador tilda la casilla “Estoy de acuerdo”, el mecanismo debe intervenir en ese preciso instante, es decir, en el sitio web del comerciante.

Los mecanismos descritos en el punto 2 permitirían que en el sitio web del comerciante se determinara si el comprador es de un Estado del Grupo I o de un Estado del Grupo II y, en caso de que sea del Grupo II, si se trata de una empresa o de un consumidor. Si se determinara que el comprador es un consumidor de un Estado del Grupo II, se ofrecería automáticamente la “vía no arbitral” (la Modalidad II) del Reglamento; de lo contrario, se ofrecería la modalidad que el comerciante ofrezca en las operaciones con otros compradores (la Modalidad II o la Modalidad I).

El enfoque señalado podría aplicarse en el Reglamento del siguiente modo:

En el Reglamento figurarían dos anexos:

- El anexo I, en el que se enumerarían los Estados del Grupo I;
- El anexo II, en el que se enumerarían los Estados del Grupo II.

Antes de que se aprobara el Reglamento, los Estados notificarían a la Secretaría de la CNUDMI si desean aparecer en el anexo I o en el anexo II.

- En el artículo 2 del proyecto de reglamento se agregaría una definición de “consumidor”. En varios instrumentos internacionales figuran definiciones de “consumidor” (por ejemplo, en el artículo 2 del Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro) que podrían servir de modelo.
- En el Reglamento se estipularía que, en caso de que el comprador sea un consumidor de un Estado del Grupo I, la Modalidad I solo podría aceptarse tras haber surgido la controversia.

Por consiguiente, el mecanismo descrito permitiría, en esencia, que en el sitio web del comerciante se eligiera si se va a ofrecer al comprador la Modalidad I o la Modalidad II del Reglamento. La implantación de ese mecanismo en los sitios web de los comerciantes que operan por Internet es muy sencilla en lo que respecta a la tecnología de la información y no constituye una carga para ellos. Al respecto, cabe observar lo siguiente:

- Todos los comerciantes que operan por Internet tienen un sitio web en el que figura un formulario de pedido que los compradores deben cumplimentar indicando su dirección (de envío y facturación). En consecuencia, los sistemas de los comerciantes ya disponen de los datos que necesitarían para determinar si el Estado del comprador pertenece al Grupo I o al Grupo II.
- La reunión de los datos necesarios para determinar si el comprador es o no es un consumidor puede efectuarse con suma facilidad: cuando el sistema determine (sobre la base de la dirección consignada por el comprador en el formulario de pedido) que el Estado del comprador es del Grupo II, debería formularse una pregunta al comprador, de conformidad con la definición de “consumidor” establecida en el artículo 2 del Reglamento, que permitiera determinar si se trata de una empresa o de un consumidor (por ejemplo, “¿Realiza usted esta compra con fines personales o profesionales?”).

-
- La conexión del resultado de la mencionada reunión de datos con la opción de la Modalidad I o la Modalidad II del Reglamento es una operación muy sencilla desde el punto de vista tecnológico.
 - Los comerciantes que operen por Internet y que deseen ofrecer el Reglamento de la CNUDMI tendrán que rehacer su sitio web de todas maneras y, de hecho, incluir un mecanismo sencillo como el que se acaba de describir no constituye una carga adicional.

IV. RÉGIMEN DE LA INSOLVENCIA

A. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia sobre la labor realizada en su 42º período de sesiones (Viena, 26 a 30 de noviembre de 2012)

(A/CN.9/763)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-4
II. Organización del período de sesiones	5-11
III. Deliberaciones y decisiones	12
IV. Interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses.	13-65
A. Finalidad y origen de la Ley Modelo	16
B. Finalidad de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación	17
C. Características principales de la Ley Modelo	18-21
D. Observaciones a cada uno de los artículos	22-65
V. Obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia	66-93
A. Finalidad de las disposiciones legislativas	67-69
B. Contenido de las disposiciones legislativas	70-90
C. Comentario	91
D. Cuestiones relativas a los directores de empresas pertenecientes a un grupo	92
E. Cuestiones transfronterizas	93
VI. Distribución de textos a los Estados para recabar sus observaciones	94
VII. Insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas	95-96
VIII. Asistencia técnica y cooperación	97-98

I. Introducción

1. En su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión tuvo ante sí una serie de propuestas sobre la posible labor futura en relación con el régimen de la insolvencia (A/CN.9/WG.V/WP.93 y Add.1 a 6 y A/CN.9/582/Add.6). Esas propuestas se habían examinado en el 38º período de sesiones del Grupo de

Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) (véase A/CN.9/691, párrafos 99 a 107) junto con una recomendación sobre posibles temas presentada a la Comisión (A/CN.9/691, párrafo 104). En otro documento (A/CN.9/709), presentado después de ese período de sesiones del Grupo de Trabajo V, se incluía material complementario a la propuesta de Suiza que figuraba en A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5.

2. Tras las correspondientes deliberaciones, la Comisión hizo suya la recomendación del Grupo de Trabajo V de que se emprendieran actividades sobre tres temas relacionados con la insolvencia: a) la interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses; b) las responsabilidades y obligaciones de los directores en situaciones de insolvencia y preinsolvencia, que eran ambos de importancia en la actualidad; y c) el material judicial relativo a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza. En su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión finalizó y aprobó la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial.

3. En su 39º período de sesiones, celebrado en 2010, el Grupo de Trabajo V inició su examen de esos tres temas, basándose en las notas preparadas por la Secretaría (A/CN.9/WG.V/WP.95 y Add.1 y A/CN.9/WG.V/WP.96). Las decisiones y conclusiones del Grupo de Trabajo figuran en el documento A/CN.9/715. El Grupo de Trabajo siguió examinando los temas a) y b) en su 40º período de sesiones, celebrado en 2011, basándose en las notas preparadas por la Secretaría (A/CN.9/WG.V/WP.99, 100 y 101), y en su 41º período de sesiones, celebrado en 2012, basándose en las notas preparadas por la Secretaría (A/CN.9/WG.V/WP.103 y Add.1, 104 y 105).

4. En su 43º período de sesiones, que tuvo lugar en junio de 2010, la Comisión examinó una propuesta de estudio de la viabilidad de un instrumento internacional de resolución transfronteriza de casos de insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5 y A/CN.9/709, párrafo 5). Se acordó que la Secretaría preparara un informe amplio sobre todas o algunas de las cuestiones planteadas en la propuesta.

II. Organización del período de sesiones

5. El Grupo de Trabajo V, compuesto por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 42º período de sesiones del 26 al 30 de noviembre de 2012 en Viena. Al período de sesiones asistieron representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Austria, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, México, Nigeria, Noruega, Pakistán, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uganda y Venezuela (República Bolivariana de).

6. Asistieron al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Belarús, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Guatemala, Indonesia, Lituania, Madagascar, Polonia, Qatar, República Dominicana y Suiza.

7. Asistieron también al período de sesiones observadores de la Unión Europea.

8. Asimismo, asistieron al período de sesiones observadores de las siguientes organizaciones internacionales:

a) *Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas*: Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial;

b) *Organizaciones intergubernamentales invitadas*: Banco Islámico de Desarrollo;

c) *Organizaciones internacionales no gubernamentales invitadas*: American Bar Association (ABA), Asociación Europea de Estudiantes de Derecho (ELSA), Asociación Internacional de Abogados, Business Recovery and Insolvency Practitioners Association of Nigeria (BRIPAN), Confederación Internacional de Mujeres Especializadas en Insolvencia y Reestructuración (IWIRC), Federación Interamericana de Abogados (FIA), Groupe de Réflexion sur l'Insolvabilité et sa Prévention (GRIP 21), INSOL International (INSOL), Instituto Europeo de Derecho (ELI), International Credit Insurance and Surety Association (ICISA), International Insolvency Institute (III), International Swaps and Derivatives Association (ISDA), New York State Bar Association (NYSBA) y Unión Internacional de Abogados (UIA).

9. El Grupo de Trabajo eligió a los siguientes delegados para integrar la Mesa:

Presidente: Sr. Wisit Wisitsora-At (Tailandia)

Relator: Sr. Carlos Lorenzo Cudas Zavala (Paraguay)

10. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí los siguientes documentos:

a) Programa provisional anotado (A/CN.9/WG.V/WP.106);

b) Una nota de la Secretaría sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos enunciados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses (A/CN.9/WG.V/WP.107);

c) Una nota de la Secretaría sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia (A/CN.9/WG.V/WP.108);

d) Una nota de la Secretaría sobre la insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas (A/CN.9/WG.V/WP.109); y

e) Una nota sobre la asistencia y cooperación técnicas (A/CN.9/WG.V/WP.110).

11. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:

1. Apertura del período de sesiones.

2. Elección de la Mesa.

3. Aprobación del programa.

4. Examen de a) la interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses; b) las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia; y c) la insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas.

5. Otros asuntos.
6. Aprobación del informe.

III. Deliberaciones y decisiones

12. El Grupo de Trabajo deliberó sobre los temas siguientes: a) la forma de dar orientación sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses; b) las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia; y c) la insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas, sobre la base de los documentos A/CN.9/WG.V/WP.107, A/CN.9/WG.V/WP.108 y A/CN.9/WG.V/WP.109. El Grupo de Trabajo examinó también cuestiones relativas a la asistencia y cooperación técnicas en relación con el régimen de la insolvencia, basándose en el documento A/CN.9/WG.V/WP.110. A continuación se recogen las deliberaciones que el Grupo de Trabajo mantuvo sobre esos temas y las decisiones que adoptó al respecto.

IV. Interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses

13. El Grupo de Trabajo inició su período de sesiones con el examen de dos cuestiones que había planteado la Comisión en su 45º período de sesiones respecto a si el mandato del Grupo de Trabajo en relación con el centro de los principales intereses abarcaba aspectos relativos a los grupos de sociedades y, de ser así, cuándo debía examinar ese tema el Grupo de Trabajo. En cuanto al alcance de su mandato en relación con el centro de los principales intereses, el Grupo de Trabajo señaló que era preciso examinar los aspectos de esa cuestión relacionados con los grupos de sociedades porque la mayor parte de la actividad comercial se llevaba a cabo por medio de esos grupos. El Grupo de Trabajo observó la descripción del mandato que figuraba en el párrafo 10 del documento A/CN.9/WG.V/WP.107 y señaló que, en su redacción original, la intención era abarcar la cuestión del centro de los principales intereses en el contexto de los grupos de sociedades. El Grupo de Trabajo recomendó que la Comisión confirmara la opinión del Grupo de Trabajo en el sentido de que el alcance del mandato del Grupo en la materia aprobado originalmente incluía la cuestión del centro de los principales intereses en el contexto de los grupos de sociedades.

14. Con respecto al momento en que debía examinarse esa cuestión, el Grupo de Trabajo convino en que sería después de introducir las modificaciones propuestas de la Guía para la incorporación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza al derecho interno en relación con el centro de los principales intereses de deudores individuales.

15. A continuación, el Grupo de Trabajo inició su examen de las propuestas de revisión de la Guía para la incorporación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la

Insolvencia Transfronteriza al derecho interno, que figuraban en el documento A/CN.9/WG.V/WP.107.

A. Finalidad y origen de la Ley Modelo

16. El Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo los párrafos 3 y 3A y las modificaciones de las notas de los párrafos 4 a 8 tal como se habían redactado.

B. Finalidad de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación

17. Se aprobó en cuanto al fondo el párrafo 9 tal como estaba redactado.

C. Características principales de la Ley Modelo

1. Acceso

18. El Grupo de Trabajo convino en que se modificaran las tres primeras oraciones del párrafo 49B insertando la palabra “both” entre la palabra “address” y la palabra “inbound” en la primera oración (modificación que no afecta a la versión en español), y las palabras “en lo que respecta a la actuación del Estado promulgante en el extranjero” y “en lo que respecta a la actuación de un representante extranjero en el Estado promulgante” al principio de las oraciones segunda y tercera, respectivamente, de forma que el texto quedara como sigue: “Las disposiciones sobre el acceso se refieren a los aspectos de los procedimientos de insolvencia transfronteriza relacionados tanto con la actuación del Estado promulgante en el extranjero como viceversa. En lo que respecta a la actuación del Estado promulgante en el extranjero, se autoriza a la persona o el órgano que administra la reorganización o liquidación con arreglo a las leyes del Estado promulgante (llamado “representante de la insolvencia”) para actuar en un Estado extranjero (artículo 5) en representación de un procedimiento abierto en su Estado. En lo que respecta a la actuación de un representante extranjero en el Estado promulgante, el representante extranjero tiene el derecho de acceso directo a los tribunales del Estado promulgante (artículo 9); ...”.

2. Reconocimiento

19. El Grupo de Trabajo convino en suprimir las palabras “entre otras cosas” en la tercera oración del párrafo 37A y en suprimir la palabra “automáticamente” de la penúltima oración del mismo párrafo e insertar las palabras “sin exigir más requisitos” al final de dicha oración. Por lo demás, se aprobó en cuanto al fondo el párrafo 37A tal como estaba redactado. Se modificó el párrafo 37B insertando una oración adicional al final del párrafo en el sentido de que la excepción de orden público debía utilizarse en una serie limitada de casos y que las diferencias entre los regímenes de la insolvencia no justificaban por sí mismas la conclusión de que la aplicación de las leyes de un Estado suponía la violación del orden público de otro Estado.

20. El Grupo de Trabajo aprobó los párrafos 37C, E y F tal como estaban redactados.

3. Cooperación y coordinación

21. El Grupo de Trabajo aprobó los párrafos 33B y 33E tal como estaban redactados.

D. Observaciones a cada uno de los artículos

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículos 1 a 8

Artículo 1. Ámbito de aplicación

22. Se aprobó el párrafo 65 tal como estaba redactado.

Artículo 2. Definiciones

23. El Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo los párrafos 68, 23A y 23A *bis* tal como estaban redactados.

Apartados a) y b)

24. El Grupo de Trabajo aprobó los párrafos 23B, 23C, 24G y 31 tal como estaban redactados.

Apartados c) a f)

25. El Grupo de Trabajo aprobó el párrafo 73 tal como estaba redactado; convino en insertar las palabras “para el tribunal” en la penúltima oración del párrafo 73A y revisar la frase en cuestión para que dijera “prueba aceptable para el tribunal”; y aprobó los párrafos 74 y 75B tal como estaban redactados.

Artículos 3, 5 y 8

26. El Grupo de Trabajo aprobó los párrafos 78, 84 y 91 tal como estaban redactados.

Capítulo II. Acceso de los representantes y acreedores extranjeros a los tribunales del Estado

Artículos 10 a 12

27. El Grupo de Trabajo aprobó los párrafos 96, 98, 100, 101 y 102 tal como estaban redactados.

Capítulo III. Reconocimiento de un procedimiento extranjero y medidas otorgables

Artículos 15 a 24

Artículo 15: Solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero

28. El Grupo de Trabajo aprobó los párrafos 119 y 120 tal como estaban redactados.

*Artículo 16. Presunciones relativas al reconocimiento**Párrafo 1*

29. Se sugirió que las dos últimas oraciones del párrafo 122B no parecían concordar plenamente con la primera oración del párrafo, en la que se alentaba a los tribunales que abrieran el procedimiento extranjero a incluir información en sus órdenes para facilitar la tarea de reconocimiento. Se propuso suprimir las dos últimas oraciones del párrafo para que quedara más claro. No obstante, el Grupo de Trabajo convino en que había querido evitar el posible problema de que un tribunal que abriera un procedimiento extranjero llegara a conclusiones que abarcaran un ámbito más amplio del necesario, lo que podría influir indebidamente en decisiones que debería adoptar de forma independiente el tribunal receptor. Se solicitó a la Secretaría que preparara un texto revisado del párrafo 122B para subsanar toda incoherencia respetando al mismo tiempo la intención del Grupo de Trabajo.

30. La Secretaría preparó el siguiente texto revisado del párrafo 122B:

“122B. Debe promoverse la inclusión de esa información en la orden del tribunal que abre el procedimiento extranjero para facilitar la tarea de reconocimiento en los casos pertinentes, si bien debe evitarse formular conclusiones acerca de cuestiones sobre las que compete al tribunal receptor decidir, como el lugar en que se encuentra el centro de los principales intereses o si el procedimiento extranjero es o no el principal*. Como se observa más adelante, esas órdenes o decisiones no son vinculantes para el tribunal del Estado promulgante que recibe la solicitud, que ha de cerciorarse por sí mismo de que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 (analizados más detenidamente en los párrafos 124B y C *infra*).

* Salvo cuando la jurisdicción dependa de la determinación del centro de los principales intereses o de la presencia de un establecimiento.”

31. Se expresó preocupación ante la posibilidad de que el texto revisado, aunque reflejaba las deliberaciones anteriores del Grupo de Trabajo, se percibiera como un texto que exigía indebidamente al tribunal iniciador adaptar sus órdenes en función del tribunal receptor y que trataba de imponer restricciones al tribunal iniciador en cuanto a las cuestiones de las que se podía ocupar. No obstante, se reconoció que podría ser útil incluir una advertencia en la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación, puesto que los jueces suelen consultar dicha Guía, así como la Guía Legislativa. Además, se convino en que la información en cuestión se referiría principalmente al procedimiento y el representante extranjeros en el sentido del artículo 16 1) de la Ley Modelo.

32. Tras las correspondientes deliberaciones, se aprobó el párrafo 122B con el siguiente texto:

“122B. La inclusión de información sobre las características del procedimiento y el representante extranjeros, tal como se definen en el artículo 2, en las órdenes del tribunal que abre el procedimiento extranjero puede facilitar la tarea de reconocimiento en los casos pertinentes. Esas órdenes o decisiones no son vinculantes para el tribunal del Estado promulgante que recibe la solicitud, que ha de cerciorarse por sí mismo de que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 (analizados más detenidamente en los párrafos 124B y C *infra*).

Párrafo 3

33. El Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo el párrafo 123A tal como estaba redactado.

34. El Grupo de Trabajo aprobó el párrafo 123B en cuanto al fondo con el siguiente cambio: se suprimieron las palabras “con frecuencia” al principio de la segunda oración y se insertaron las palabras “en esa situación” delante de las palabras “no surgirá ningún motivo”.

35. El Grupo de Trabajo aceptó la recomendación que figuraba en la nota 6 del documento A/CN.9/WG.V/WP.107 en el sentido de que habría que suprimir la palabra “prueba” en la primera oración del párrafo 123C y utilizar las palabras “convencer al tribunal”. Se aprobó el párrafo 123C con la modificación propuesta.

Centro de los principales intereses

36. El Grupo de Trabajo expresó su preferencia por la segunda versión del párrafo 123D, con las modificaciones siguientes: a) colocar la tercera oración, relativa al Reglamento de la Comunidad Europea¹, en una nota al pie; y b) incorporar las oraciones tercera y cuarta de la primera versión del párrafo 123E. El Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría que preparara una versión revisada del párrafo para proseguir el examen.

37. La Secretaría preparó el siguiente texto revisado del párrafo 123D:

“123D. El concepto de centro de los principales intereses del deudor es fundamental para el funcionamiento de la Ley Modelo*. Esta asigna más importancia al procedimiento entablado en el lugar en que se encuentra y también prevé que en él se dicten medidas cautelares automáticas y más inmediatas. Los atributos esenciales del centro de los principales intereses del deudor se corresponden con los atributos que permitirán a quienes hagan negocios con el deudor (especialmente a los acreedores) averiguar el lugar en que este podría abrir el procedimiento de insolvencia. Tal como se ha señalado, en la Ley Modelo se establece una presunción de que el lugar al que corresponden esos atributos es el lugar en que la empresa está inscrita. Sin embargo, en realidad, el lugar en que se encuentra el centro de los principales intereses del deudor puede no coincidir con el lugar de inscripción, y la Ley Modelo prevé la posibilidad de impugnar la presunción si estuviera en otro lugar. Si el centro de los principales intereses del deudor no está situado en el lugar de inscripción, deberá determinarse teniendo en cuenta otros factores que indiquen a quienes hacen negocios con el deudor (especialmente a los acreedores) dónde está. Así pues, es importante tener en cuenta los factores que, de por sí, pueden indicar que el centro de los principales intereses del deudor está situado en determinado Estado.

* Como se señala en el párrafo 31A, el concepto de centro de los principales intereses también es básico en el Reglamento del Consejo de la Unión Europea.”

¹ Reglamento (CE) núm. 1346/2000 del Consejo de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia.

38. Tras deliberar sobre el texto revisado, el Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo con el fondo el párrafo 123D, con las siguientes modificaciones: a) en la tercera oración, sustituir la frase “en que este podría abrir el procedimiento de insolvencia” por la frase “en que se podría abrir el procedimiento de insolvencia relacionado con el deudor”; y b) al comienzo de la sexta oración, sustituir la frase “Si el centro de los principales intereses del deudor no está situado en el lugar de inscripción,” por la frase “Si no se sabe con certeza que el centro de los principales intereses del deudor está situado en el lugar de inscripción,”.

Factores pertinentes para determinar el centro de los principales intereses

39. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en que debían mantenerse los factores a) y b) del párrafo 123F como los más importantes, y también los principales, para determinar el centro de los principales intereses. También convino en que el factor a) debía referirse a si el lugar era fácil de averiguar para los acreedores, puesto que estos formaban el grupo más importante de interesados, y que debía suprimirse la palabra “terceros”. En cuanto al factor b), se decidió que la determinación del lugar debía basarse en si se trataba de la administración central del deudor y que debían suprimirse las palabras “o las operaciones” y la palabra “administración”. Con respecto al factor c), el Grupo de Trabajo convino en que si bien era menos importante que los factores a) y b), debía mantenerse porque podría resultar útil para determinar el centro de los principales intereses, y debía incluirse en el párrafo 123I en lugar de suprimirse.

40. El Grupo de Trabajo también convino en que no se pretendía que el párrafo 123I fuera una lista exhaustiva, que el orden en que se citaban los factores en ese párrafo no suponía que hubiera que otorgarles ninguna importancia o peso en particular y que la primera oración del párrafo 123I debía referirse a los factores “principales”.

41. Se deliberó sobre el orden en que debían figurar los párrafos 123F, G e I. En vista de las decisiones adoptadas con respecto a los factores en los párrafos 123F e I, se solicitó a la Secretaría que examinara si habría que suprimir algo del párrafo 123G y dónde habría de colocarse dicho párrafo.

42. La Secretaría preparó el siguiente texto revisado del párrafo 123F, que fue aprobado por el Grupo de Trabajo:

“123F. En la mayoría de los casos, los factores principales que se exponen a continuación, considerados globalmente, tenderán a indicar si el lugar en que se abrió el procedimiento es aquel en que se encuentra el centro de los principales intereses del deudor. Los factores que han de tenerse en cuenta son: a) si el lugar es fácil de averiguar para los acreedores, y b) si se trata del lugar en que se encuentra la administración central del deudor.”

43. La Secretaría preparó el siguiente texto revisado de los párrafos 123G y 123I:

“123G. Con frecuencia esos factores coincidirán en señalar que el centro de los principales intereses se encuentra en una determinada jurisdicción. En algunos casos, sin embargo, puede haber conflictos entre los factores, lo que hará necesario que se estudien más detenidamente los hechos. Así pues, se trata de establecer los hechos, y el tribunal analizará diversos factores para determinar con toda la objetividad posible dónde se encuentra el centro de los

principales intereses de un deudor concreto. En todas las situaciones, el proceso de búsqueda es integral y tiene por objeto determinar que el lugar del procedimiento extranjero se corresponde efectivamente con el del centro de los principales intereses del deudor.

123I. Cuando los factores principales mencionados no se prestan para determinar fácilmente el centro de los principales intereses del deudor, pueden considerarse otros elementos relativos a los negocios del deudor. El tribunal podrá tener que dar mayor o menor peso a un determinado factor, en función de las circunstancias del caso. Entre esos otros factores pueden figurar los siguientes: [...]. El orden en que figuran estos factores no indica la prioridad o el peso que se les ha de otorgar ni supone una enumeración exhaustiva de los factores pertinentes; el tribunal podrá tener en cuenta otros factores que puedan aplicarse según el caso particular.”

44. Se observó que tras la aprobación del texto revisado del párrafo 123F, era preciso introducir los cambios consiguientes en los párrafos 123G y 123I en vista de que ahora solo se mencionaban dos factores en el párrafo 123F. Se convino en que, al hacer esas revisiones, se debía mantener un énfasis adecuado en el carácter integral del análisis de los factores. El Grupo de Trabajo convino en el siguiente texto revisado de los párrafos 123G y 123I :

“123G. Cuando los factores principales mencionados no se prestan para determinar fácilmente el centro de los principales intereses del deudor, pueden considerarse otros elementos relativos a los negocios del deudor. El tribunal podrá tener que dar mayor o menor peso a un determinado factor, en función de las circunstancias del caso. No obstante, en todas las situaciones, el proceso de búsqueda es integral y tiene por objeto determinar que el lugar del procedimiento extranjero se corresponde efectivamente con el centro de los principales intereses del deudor.

123I. El orden en que a continuación figuran esos otros factores no indica la prioridad o el peso que se les ha de otorgar ni supone una enumeración exhaustiva de los factores pertinentes; el tribunal podrá tener en cuenta otros factores que puedan aplicarse según el caso particular. Entre esos otros factores pueden figurar los siguientes: [...].”

Traslado del centro de los principales intereses

45. El Grupo de Trabajo convino en que los párrafos 123K y L podían simplificarse para reflejar las ideas de que podría trasladarse el centro de los principales intereses del deudor (en lugar de su lugar de inscripción); de que si el cambio se producía en fecha muy próxima a la apertura del procedimiento de insolvencia podría ser más difícil cumplir los factores mencionados en el párrafo 123F; y de que el tribunal debía examinar más atentamente esos factores en relación con un deudor que se encontrara en esa posición para asegurarse de tomar una decisión adecuada en cuanto al reconocimiento. También se convino en que el traslado del centro de los principales intereses del deudor no debía dar lugar a la presunción de fraude. El Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría que preparara una versión revisada de los párrafos para proseguir el examen.

46. La Secretaría preparó el siguiente texto revisado del párrafo 123K:

“123K. En algunos casos el deudor ha cambiado el centro de sus principales intereses en fecha muy próxima a la apertura del procedimiento de insolvencia, incluso entre la fecha de solicitud de apertura y la apertura efectiva del procedimiento. Algunas veces el traslado tuvo por objeto dar acceso al deudor a un proceso de insolvencia, por ejemplo, de reorganización, que atendiera más a sus necesidades que el que le ofrecían las leyes de la jurisdicción en que se encontraba el centro de sus principales intereses. En otros casos, el traslado del lugar de inscripción (o de la residencia habitual) puede haber tenido por objeto frustrar las expectativas legítimas de los acreedores y los terceros, o haberse hecho aprovechando información confidencial o por motivos subjetivos. Por regla general, siempre que se compruebe que el cambio ha ocurrido en fecha muy próxima a la apertura del procedimiento extranjero, puede ser conveniente que el tribunal receptor, para decidir si reconoce o no el procedimiento, considere más cuidadosamente los factores mencionados en el párrafo [...] y tenga en cuenta las circunstancias del deudor de manera más amplia. En particular, la condición de que los terceros puedan averiguar fácilmente cuál es el centro de los principales intereses será más difícil de cumplir si el traslado de este ha tenido lugar en una fecha próxima a la apertura del procedimiento.”

47. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en que en la primera oración la frase “En algunos casos el deudor ha cambiado el centro de sus principales intereses” se sustituyera por la frase “El centro de los principales intereses del deudor puede cambiar antes de la apertura del procedimiento de insolvencia; en algunos casos”, y que al comienzo de la penúltima oración se suprimiera la expresión “Por regla general,”. El Grupo de Trabajo no llegó a un acuerdo sobre la disyuntiva de incluir o no las oraciones segunda y tercera del párrafo 123K: algunos indicaron que los ejemplos mencionados en esas oraciones eran útiles como demostración de dos extremos posibles, en tanto que otros fueron de la opinión de que la inclusión de esos ejemplos podría dar lugar a un examen de la cuestión innecesario y posiblemente subjetivo. Como solución de avenencia, se convino en que las oraciones segunda y tercera se incluyeran como notas de pie de página entre corchetes, y que, en la tercera oración, la expresión “centro de los principales intereses” se reemplazara por la expresión “el lugar de inscripción (o de la residencia habitual)”. Se acordó también que las referencias pertinentes remitieran a los factores indicados en los párrafos 123F y 123I.

48. Se aprobó en cuanto al fondo el párrafo 123M tal como estaba redactado.

Artículo 17. Resolución de reconocimiento de un procedimiento extranjero

Párrafo 1

49. En los párrafos 124B y C, el Grupo de Trabajo convino en mantener la referencia a “información” y suprimir la referencia a “prueba”. Con esa modificación, el Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo esos párrafos tal como estaban redactados.

*Párrafo 2**Momento de determinar el centro de los principales intereses*

50. Se aprobaron en cuanto al fondo los párrafos 128A y B tal como estaban redactados.

51. El Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo el párrafo 128C con las modificaciones siguientes: a) sustituir las palabras “el deudor dejó de comerciar” por una referencia al cese de la actividad empresarial del deudor; b) suprimir la segunda oración, relativa al Reglamento del Consejo de la Unión Europea; y c) sustituir las palabras “La misma cuestión” al principio de la quinta oración por las palabras “El mismo razonamiento”.

52. El Grupo de Trabajo convino en que la cuestión del momento de determinar el centro de los principales intereses también debía aplicarse al establecimiento. Se solicitó a la Secretaría que incluyera texto apropiado para reflejar esa decisión.

53. Además, se convino en que el texto no necesitaba añadir más explicaciones del concepto de residencia habitual.

Abuso del proceso

54. Se señaló que el texto del párrafo 123L relativo a las declaraciones falsas sobre la ubicación del centro de los principales intereses debía incluirse en el párrafo 123J. No recibió apoyo la sugerencia de trasladar el párrafo 123J a las observaciones sobre el artículo 6.

Párrafos 3 a 4

55. El Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo los párrafos 125, 130 y 131 tal como estaban redactados.

*Artículo 18. Información subsiguiente**Incisos a) y b)*

56. El Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo los párrafos 133 y 134 tal como estaban redactados.

*Artículo 19. Medidas otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero**Párrafos 1 a 4*

57. Se aprobaron en cuanto al fondo los párrafos 135 a 140 tal como estaban redactados.

*Artículo 20. Efectos del reconocimiento de un procedimiento extranjero principal**Párrafos 1 a 4*

58. El Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo los párrafos 144 a 146, 149 y 151 a 153 tal como estaban redactados.

Artículo 21. Medidas otorgables a partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero

59. Se aprobaron en cuanto al fondo los párrafos 154, 156, 158 y 160 tal como estaban redactados.

Artículo 22. Protección de los acreedores y de otras personas interesadas

60. El Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo los párrafos 162 a 164 tal como estaban redactados.

Artículo 23. Acciones de impugnación de actos perjudiciales para los acreedores

61. Se aprobaron en cuanto al fondo los párrafos 165 a 167 tal como estaban redactados.

Artículo 24. Intervención de un representante extranjero en procedimientos que se sigan en este Estado

62. El Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo el párrafo 170 tal como estaba redactado.

Capítulo IV. Cooperación con tribunales y representantes extranjeros

Artículo 27. Formas de cooperación

63. Se aprobaron en cuanto al fondo los párrafos 183 y 183A tal como estaban redactados.

Capítulo V. Procedimientos paralelos

Artículo 28. Apertura de un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia] tras el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal

64. El Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo los párrafos 185 y 187A tal como estaban redactados.

Capítulo VI. Asistencia de la secretaría de la CNUDMI

B. Información sobre interpretación de normas legales basadas en la Ley Modelo

65. Se aprobaron en cuanto al fondo los párrafos 201 y 202 tal como estaban redactados.

V. Obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia

66. El Grupo de Trabajo reanudó su examen del tema de las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia basándose en el documento A/CN.9/WG.V/WP.108.

A. Finalidad de las disposiciones legislativas

67. La Secretaría señaló a la atención del Grupo de Trabajo dos cuestiones que habían de examinarse en relación con la finalidad de las disposiciones legislativas. La primera tenía que ver con la elección de un término o una descripción aplicable a las personas que se encargarían de tomar las medidas necesarias para evitar la insolvencia o reducir al mínimo sus efectos. La segunda cuestión se refería al uso de las palabras “posible”, “inminente” o “inevitable” para describir el período previo a la insolvencia dentro del cual debían cumplirse las obligaciones o funciones.

68. En cuanto al término o descripción que había de darse a las personas de una empresa que se encargarían de adoptar las medidas necesarias, se convino en que debería utilizarse una descripción más genérica, como “los encargados de adoptar decisiones acerca de la gestión de la empresa”, puesto que la palabra “directores” tenía distintos significados en las diferentes jurisdicciones y la descripción genérica abarcaría a las personas que no fueran directores de hecho pero que tomaban decisiones en representación de la empresa. El Grupo de Trabajo convino en utilizar una descripción más genérica con una modificación para sustituir las palabras “los encargados de adoptar” por las palabras “quienes adoptan”. Ese cambio debía reflejarse en todos los proyectos de recomendación.

69. Con respecto al uso de las palabras “posible,” “inminente” o “inevitable,” el Grupo de Trabajo convino en suprimir la palabra “posible” y en utilizar las palabras “inminente o inevitable”. Ese cambio debía reflejarse en todos los proyectos de recomendación.

B. Contenido de las disposiciones legislativas

Recomendación 1 - La obligación

70. El Grupo de Trabajo convino en que debían mantenerse en todos los proyectos de recomendación las palabras “La ley relativa a la insolvencia”. Dado que esa formulación difería de las referencias a “El régimen de la insolvencia” que figuraban en las partes primera, segunda y tercera de la Guía Legislativa, debía incluirse texto para explicar que se había adoptado una formulación más amplia a fin de tener en cuenta la pertinencia de otros textos legislativos, en particular el derecho de sociedades, en lo que respecta a las obligaciones de los directores.

71. Se expresaron diversas opiniones respecto al párrafo 2 del proyecto de recomendación 1 y las medidas que habían de adoptarse, teniendo en cuenta el objetivo de alentar a los directores a que utilizaran la reorganización y procedimientos oficiosos apropiados a su debido tiempo, la necesidad de ampliar el enfoque de los directores para incluir los intereses de los acreedores y la conveniencia de especificar las medidas aplicables propiamente al período cercano a la insolvencia, en lugar de las medidas que solían incluirse entre las obligaciones generales de un director. Se sugirió que podrían agruparse las medidas razonables en varias fases, como las relativas a la evaluación de la situación de la empresa, la determinación de las opciones de que podría disponer la empresa para evitar la insolvencia o, si esta fuera inevitable, reducir al mínimo sus efectos y, por último, la adopción de medidas apropiadas. Se propuso que el párrafo 32 del comentario examinara las medidas razonables con cierto grado de detalle y sirviera de base para la revisión de

la recomendación 1, párrafo 2. Se sugirió que si bien evitar la insolvencia y reducir al mínimo sus efectos cuando esta fuera inevitable eran situaciones diferentes que podrían requerir medidas distintas, muchas de las medidas que deberían adoptarse en cualquiera de los casos tenían elementos en común, y no hacía falta que hubiera distintos conjuntos de medidas.

72. Se expresó preocupación por el hecho de que incluir una obligación de evitar operaciones que pudieran ser anulables en caso de que se iniciara un procedimiento de insolvencia podría constituir un motivo para incurrir en responsabilidad que no solía existir en las disposiciones en materia de impugnación. En respuesta, se sugirió que como la Guía Legislativa sobre el régimen de la insolvencia establecía un mecanismo para anular determinadas operaciones, era apropiado incluir en este texto una obligación de evitar ese tipo de operaciones cuando esas operaciones no tuvieran una justificación razonable desde el punto de vista empresarial. Se convino en que el proyecto de recomendación 1 debía hacer referencia a “obligaciones”, dado que se refería a más de una obligación, y en que debía reflejarse esa modificación en todos los proyectos de recomendación.

73. Tras las correspondientes deliberaciones, se solicitó a la Secretaría que preparara un texto revisado, teniendo en cuenta las cuestiones que se habían tratado, para proseguir el examen.

74. La Secretaría preparó el siguiente texto revisado de la recomendación 1:

“1. La ley relativa a la insolvencia debería especificar que, a partir del momento mencionado en la recomendación 2, la persona citada en la recomendación 3 tendrá la obligación de tener debidamente en cuenta los intereses de los acreedores y demás interesados, así como la obligación de adoptar medidas razonables para:

- a) evitar la insolvencia; y
- b) cuando la insolvencia sea inevitable, reducir al mínimo su alcance.

2. Entre las medidas razonables podrán figurar las siguientes:

a) Evaluar la situación financiera de la empresa y asegurar que las cuentas se lleven debidamente y estén actualizadas; informarse de manera independiente acerca de la situación financiera en que se encuentra la empresa y su situación general; celebrar reuniones periódicas del consejo de administración para vigilar la situación; obtener asesoramiento profesional, incluso asesoramiento jurídico o relativo a la insolvencia; mantener conversaciones con los auditores; convocar una asamblea de accionistas;

b) Evaluar las opciones que podría tener la empresa para evitar la insolvencia o, si esta fuera inevitable, reducir al mínimo sus efectos, y modificar las prácticas de gestión para tener en cuenta los intereses de una variedad de partes interesadas; proteger los activos de la empresa para obtener el máximo valor y evitar la pérdida de activos fundamentales; estudiar la estructura y las funciones de la empresa para examinar la viabilidad y reducir los gastos; no permitir que la empresa se comprometa a concertar determinados tipos de operaciones que podrían ser anuladas a no ser que ello se justifique debidamente desde el punto de vista empresarial;

c) Adoptar medidas apropiadas, incluso seguir comerciando en las circunstancias en que resulte apropiado hacerlo, para obtener el máximo valor del negocio en marcha; mantener negociaciones con los acreedores o iniciar otros procedimientos oficiosos; iniciar un procedimiento oficial de reorganización o liquidación.”

75. El Grupo de Trabajo aprobó el texto del párrafo 1 tal como estaba redactado.

76. Con respecto al párrafo 2, el Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo las medidas previstas, con los pocos cambios que se señalan a continuación: ajustar el lenguaje del párrafo b) relativo a “los intereses de una variedad de partes interesadas” al texto utilizado en el encabezamiento del párrafo 1 a fin de asegurar que se dé prioridad a los intereses de los acreedores; y añadir texto al final del párrafo c) relativo al inicio de un procedimiento oficial para aclarar que dicho procedimiento solo ha de iniciarse cuando resulte apropiado, pero teniendo en cuenta también las jurisdicciones en que pueda ser obligatorio iniciar tal procedimiento en algunas situaciones. Con respecto a esto último, se sugirió que la forma en que se tratara la cuestión en la recomendación 1 debía ajustarse a la forma en que se trataba en la segunda parte de la Guía Legislativa.

77. En cuanto a la estructura de los apartados a) a c) del párrafo 2, se expresó preocupación por que, al poder aplicarse las medidas enumeradas en esos apartados a las dos situaciones previstas en el párrafo 1, no debería hacerse distinción entre esas dos situaciones en cuanto a las medidas razonables que podrían adoptarse. No obstante, también se señaló que tal vez sería más apropiado iniciar un procedimiento oficial cuando la insolvencia fuera inevitable y que podría resultar más apropiado adoptar otras medidas en los casos en que se pudiera evitar la insolvencia. El Grupo de Trabajo convino en que tal vez se podrían fusionar las medidas enumeradas en el párrafo 2, apartados a) y b), con las dos primeras medidas enumeradas en el apartado c). El inicio de un procedimiento oficial se debería tratar por separado y habría que tener en cuenta si esa medida era apropiada dada la situación financiera de la empresa, así como toda obligación de iniciar tal procedimiento que pudiera existir según la legislación nacional, como se señala más arriba. Se solicitó a la Secretaría que preparara un nuevo texto revisado de la recomendación para su examen en un futuro período de sesiones.

Recomendación 2 - ¿Cuándo nacen las obligaciones?

78. El Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de recomendación con la supresión de la palabra “probable”.

Recomendación 3 - Partes en que recaen las obligaciones

79. El Grupo de Trabajo convino en modificar el proyecto de recomendación 3 suprimiendo los corchetes de las palabras “la persona”, suprimiendo las palabras “cualquier persona que, en virtud de las definiciones del derecho nacional, cumpla la función de un director” y “que asuma las responsabilidades de un director” y manteniendo las palabras “un director designado oficialmente o cualquier otra persona que ejerza el control *de facto* y que ejerza las funciones de un director”. Los demás proyectos de recomendación también deberían utilizar la frase “la persona en quien recae la obligación”. La recomendación modificada diría lo siguiente:

“3. La ley relativa a la insolvencia debería especificar la persona en quien recae la obligación, que puede tratarse de un director designado oficialmente o cualquier otra persona que ejerza el control *de facto* y que ejerza las funciones de un director.”

Recomendación 4 - Responsabilidad

80. Con respecto al apartado 1, el Grupo de Trabajo convino, tras sus deliberaciones, en lo siguiente: debían mantenerse las palabras “los acreedores han sufrido pérdidas o perjuicios” y suprimirse las palabras “los intereses de los acreedores se han visto perjudicados”; y debían suprimirse las palabras “ocurrido en el período mencionado en la recomendación 2”.

81. Con esas modificaciones, se aprobó en cuanto al fondo el proyecto de recomendación 4.

Recomendación 5 - Elementos de la responsabilidad y excepciones

82. El Grupo de Trabajo convino en que si bien los aspectos de la recomendación relativos al proyecto de recomendación 1 tendrían que examinarse una vez que se hubiera revisado y aprobado la recomendación, debían mantenerse las palabras “una pérdida o daño a los acreedores” y suprimirse las palabras “un perjuicio a los intereses de los acreedores”. El Grupo de Trabajo también convino en que debía suprimirse la última oración del proyecto de recomendación.

Recomendación 6 - Recursos

83. Tras las correspondientes deliberaciones, el Grupo de Trabajo convino en que, con respecto a la primera oración del proyecto de recomendación: a) había que dejar claro que el pago no tendría que efectuarse hasta después de que se dirimiera la cuestión de la responsabilidad del director y que los daños y perjuicios en cuestión los fijaría el tribunal; b) toda indemnización que debiera pagarse estaría vinculada a la responsabilidad descrita en la recomendación 4, párrafo 2; y c) los recursos oponibles por responsabilidad “deberían” incluir el pago completo a la masa de la insolvencia. Con respecto a la segunda oración, se expresó la preocupación de que la formulación era demasiado amplia, al referirse en términos generales a los derechos y demandas de una forma que podría impedir a los directores ejercer sus derechos como acreedores y participar en los procedimientos ordinarios de insolvencia en el período anterior a que se entablara cualquier procedimiento con respecto al proyecto de recomendación 1. Se propuso que el proyecto de recomendación se limitara a restringir el derecho del director al resarcimiento. A ese respecto, se propuso que se empleara la formulación original que figuraba en el proyecto de recomendación 7, párrafo c), de A/CN.9/WG.V/WP.104 -“Una limitación del ejercicio de compensación con respecto a toda deuda que la empresa tenga con el director”. Esa propuesta recibió apoyo.

84. Se volvió a expresar preocupación por la cuestión del resarcimiento planteada en la recomendación 6, particularmente respecto a la distinción entre los aspectos del resarcimiento previos y los posteriores a la solicitud en la medida en que estos guardaban relación con las obligaciones y la responsabilidad de los directores, y a la pertinencia, por ejemplo, del seguro del director. Se señaló que era difícil definir el resarcimiento y que este podía adoptar distintas formas, tanto en el aspecto jurídico

como en el de la equidad, y planteaba cuestiones importantes relacionadas con la oportunidad, así como cuestiones de conducta. La incertidumbre que causaba la idea del resarcimiento podría resolverse mediante el uso de la subordinación. Se sugirió que esas cuestiones podrían examinarse más a fondo en el comentario o en una nota al pie de la recomendación 6. Se solicitó a la Secretaría que preparara un texto revisado en el que se tuvieran en cuenta las cuestiones tratadas, a fin de proseguir el examen.

Recomendación 7 - Sustanciación del procedimiento por incumplimiento de la obligación

85. Se aprobó en cuanto al fondo el proyecto de recomendación con la adición de una remisión a la recomendación 4.

Recomendaciones 8 y 9 - Financiación de los procedimientos por incumplimiento de la obligación

86. El Grupo de Trabajo aprobó en cuanto al fondo los proyectos de recomendación 8 y 9.

Recomendación 10 - Medidas adicionales

87. Se expresaron opiniones divergentes sobre la segunda oración que figuraba entre corchetes. Unos opinaron que las sanciones económicas previstas en el proyecto de recomendación 6 debían complementarse con otras medidas para impedir el mal comportamiento por parte de los directores y proteger al público de directores que hubieran actuado de forma negligente o indebida. Otros señalaron que debían incluirse otros ejemplos además de la inhabilitación. Hubo quienes argumentaron que ese tipo de restricción no estaba justificada, dado que resultaría punitiva, violaría varios derechos constitucionales, desalentaría a personas competentes de aceptar cargos de director y caería fuera del ámbito del régimen de la insolvencia. Tras las correspondientes deliberaciones, el Grupo de Trabajo convino en que debía suprimirse la segunda oración.

88. En cuanto a la primera oración, algunos temían que la supresión de la segunda le restara gran parte de su significado. Recibió cierto grado de apoyo la idea de suprimir totalmente la recomendación 10 y mantener la recomendación 6 como único recurso. Por otra parte, hubo quienes propusieron que se mantuviera la primera oración a fin de indicar que los Estados podrían incluir en su legislación nacional medidas adicionales al pago de un resarcimiento. Se sugirió que toda recomendación revisada debería referirse a las características, duración y proporcionalidad de esas medidas. El Grupo de Trabajo convino en suprimir la primera oración tal como estaba redactada, y estudiar otras propuestas.

89. La Secretaría preparó el siguiente texto revisado de la recomendación 10:

“10. Para desalentar todo comportamiento que pueda dar lugar a la responsabilidad según lo dispuesto en la recomendación 4, la ley relativa a la insolvencia podrá incluir otros recursos además del pago [de un resarcimiento] [por daños y perjuicios] previsto en la recomendación 6.

* Los recursos adicionales de que se podrá disponer dependerán de los tipos de recursos que haya disponibles en una determinada jurisdicción y de lo que,

además del pago del resarcimiento, resulte proporcional al comportamiento en cuestión y apropiado en las circunstancias del caso particular. Se examinan ejemplos de esos recursos en los párrafos --- [del comentario].”

90. En su examen del texto revisado, se recordó al Grupo de Trabajo que la Guía Legislativa ya contenía recomendaciones de estructura parecida que simplemente advertían de una cuestión importante. Se expresaron distintas opiniones sobre si se debía insertar el texto como recomendación o si se debía incluir en el comentario. Entre otras cosas, se señaló que tales medidas solían formar parte del régimen de la insolvencia; que caían fuera del ámbito del régimen de la insolvencia y pertenecían, por ejemplo, al ámbito del derecho de sociedades; o que, por el contrario se trataba de un terreno poco definido que requería un examen más detallado que se centrara exclusivamente en cuestiones de fondo sin hacer referencia a los enfoques nacionales. En apoyo de esta última opinión, se señaló que una recomendación al respecto podría resultar esclarecedora e instructiva. Tras las correspondientes deliberaciones predominó la opinión a favor de que se examinara la recomendación junto con su nota al pie en un futuro período de sesiones.

C. Comentario

91. A continuación el Grupo de Trabajo pasó a examinar el proyecto de comentario sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia, que figuraba en el documento A/CN.9/WG.V/WP.108, párrafos 6 a 51. El Grupo de Trabajo convino en que se debía reestructurar el comentario para reflejar el orden de las recomendaciones e insertar dichas recomendaciones después de las secciones correspondientes del comentario. Además, se señalaron varios casos en los que la terminología utilizada en el comentario difería de la que se había acordado para las recomendaciones, o de la que figuraba en la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia, o casos en que debía ajustarse la redacción para concordar con el acuerdo alcanzado sobre las recomendaciones. Se solicitó a la Secretaría que tuviera en cuenta las observaciones del Grupo de Trabajo al preparar el texto revisado del comentario.

D. Cuestiones relativas a los directores de empresas pertenecientes a un grupo

92. El Grupo de Trabajo examinó las cuestiones relativas a los directores de empresas pertenecientes a un grupo. Se convino en que si bien el tema planteaba cuestiones difíciles y complejas, particularmente en cuanto a los aspectos que vinculaban a la insolvencia y el derecho de sociedades, la posibilidad de una futura labor al respecto merecía examinarse con suma atención. El Grupo de Trabajo convino en que una vez que hubiera terminado su examen de las recomendaciones 1 a 10 y el comentario correspondiente, podría plantearse si abordar o no las cuestiones que podrían ser pertinentes en el contexto de los grupos de sociedades. Para facilitar esas deliberaciones se solicitó a la Secretaría que presentara información complementaria, en particular sobre los distintos enfoques y soluciones nacionales que podrían servir de base para el examen del Grupo de Trabajo.

E. Cuestiones transfronterizas

93. El Grupo de Trabajo convino en aplazar su examen de esas cuestiones a un futuro período de sesiones.

VI. Distribución de textos a los Estados para recabar sus observaciones

94. El Grupo de Trabajo pidió que se le suministraran, para su examen en el próximo período de sesiones, las versiones revisadas refundidas de los textos referentes tanto al centro de los principales intereses como a las obligaciones de los directores, en los que se hubiesen incorporado todas las revisiones acordadas. El Grupo de Trabajo observó que, una vez que hubiese examinado esos textos, se podrían distribuir a los Estados para recabar sus observaciones con anterioridad a una posible aprobación por la Comisión en su 46° período de sesiones en 2013.

VII. Insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas

95. El Grupo de Trabajo examinó ese tema sobre la base del documento A/CN.9/WG.V/WP.109, en particular con referencia a las cuestiones sometidas a su consideración en el párrafo 64 de ese documento. El Grupo de Trabajo acogió con beneplácito el resumen sumamente útil que se ofrecía en ese documento acerca de la labor realizada hasta ese momento por las organizaciones internacionales y, en particular, el examen exhaustivo que se hacía de la manera en que esas organizaciones utilizaban la labor realizada por la CNUDMI en las esferas de la insolvencia transfronteriza y los grupos de sociedades.

96. El Grupo de Trabajo convino en que sería muy útil que la Secretaría siguiera observando la labor de esas otras organizaciones, tal vez centrándose especialmente en sus aspectos transfronterizos, y que preparara otros documentos al respecto para tener al corriente de esa labor al Grupo de Trabajo y a la Comisión, siempre y cuando se dispusiera de recursos suficientes. Se destacó la necesidad de evitar la duplicación de tareas y se señaló la conveniencia de limitarse a estudiar los sectores en que el Grupo de Trabajo gozaba de especial competencia y pericia. Se observó que, prácticamente de la misma manera en que la labor de la CNUDMI en relación con la insolvencia transfronteriza y los grupos de sociedades había documentado la labor de las instituciones examinadas en el documento de trabajo, los trabajos que estas realizaran en relación con la insolvencia de las instituciones financieras podrían documentar la labor ulterior del Grupo de Trabajo con respecto al centro de los principales intereses y los grupos de sociedades. También se señaló la conveniencia, tal vez, de promover la cooperación y la coordinación entre la CNUDMI y las organizaciones internacionales que se dedicaban a estudiar la insolvencia de las instituciones financieras. Otra ventaja de observar la evolución de los estudios relativos a la insolvencia de las instituciones financieras era el hecho de que la crisis financiera mundial había impulsado considerablemente la reforma legislativa y la promulgación de leyes, lo que podía servir de base para determinar si los criterios y soluciones previstos en la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia seguían siendo pertinentes.

VIII. Asistencia técnica y cooperación

97. A continuación, el Grupo de Trabajo examinó cuestiones relativas a la asistencia técnica y la cooperación expuestas en el documento A/CN.9/WG.V/WP.110. Se informó de que el Banco Mundial utilizaba ampliamente en sus actividades de cooperación técnica los textos de la CNUDMI sobre la insolvencia y que la Unión Europea remitía regularmente a esos textos en la actual revisión de su reglamento de la insolvencia. Se señaló que el Décimo Coloquio judicial multinacional, organizado conjuntamente por la CNUDMI, INSOL y el Banco Mundial, se celebraría en La Haya en 2013, y que los participantes habían demostrado ser activos promotores de los textos de la CNUDMI sobre la insolvencia.

98. Se observó que se podría mejorar la accesibilidad de los textos de la CNUDMI sobre la insolvencia mediante su traducción a un mayor número de idiomas y que varios Estados ya habían llevado a cabo ese tipo de traducciones. Se alentó a la CNUDMI a continuar atenta a las oportunidades de cooperación con entidades pertinentes como el Banco Mundial y el FMI, y a estudiar las oportunidades de sensibilización y asistencia técnica que ofrecía la mayor integración económica en grupos regionales como la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Se invitó también a los miembros del Grupo de Trabajo a dar a conocer en mayor grado en sus respectivos Estados los textos de la CNUDMI sobre la insolvencia y a promover su adopción. Además, el Grupo de Trabajo convino en que sus miembros mantuvieran a la Secretaría al corriente de nuevos casos en que se hubiesen adoptado o utilizado los textos sobre la insolvencia, particularmente cuando se tratara de la Guía Legislativa, cuya utilización era más difícil de rastrear que la de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza.

B. Nota de la Secretaría sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos enunciados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses (COMI), presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 42º período de sesiones

(A/CN.9/WG.V/WP.107)

[Original: inglés]

Índice

Página

Introducción	
GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNO Y LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA	
I. FINALIDAD Y ORIGEN DE LA LEY MODELO	
II. FINALIDAD DE LA GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNO Y LA INTERPRETACIÓN	
III. LA LEY MODELO COMO VEHÍCULO DE ARMONIZACIÓN DEL DERECHO	
IV. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA LEY MODELO	
V. OBSERVACIONES A CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS	
VI. ASISTENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CNUDMI	

Introducción

1. En su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión tuvo ante sí una serie de propuestas sobre la labor futura en relación con el régimen de la insolvencia (A/CN.9/WG.V/WP.93 y Add.1 a 6 y A/CN.9/582/Add.6). Esas propuestas se habían examinado en el 38º período de sesiones del Grupo de Trabajo V (véase A/CN.9/691, párrs. 99 a 107) y se había hecho una recomendación a la Comisión sobre los posibles temas (A/CN.9/691, párr. 104). En otro documento (A/CN.9/709) presentado después de ese período de sesiones se añadió material a la propuesta de Suiza que figuraba en el documento A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5.

2. Tras deliberar, la Comisión hizo suya la recomendación del Grupo de Trabajo V de que se empezaran a tratar dos temas relacionados con la insolvencia que tenían importancia en la actualidad y con respecto a los cuales un mayor grado de armonización de las reglamentaciones pertinentes de los distintos Estados serviría para introducir más certeza y previsibilidad.

3. En la presente nota se examina el primero de esos dos temas, relativo a una propuesta de los Estados Unidos consignada en el párrafo 8 del documento A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.1, en la que se recomienda dar orientación sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de

la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza (la Ley Modelo) relacionados con el centro de los principales intereses y, posiblemente, elaborar una ley modelo o disposiciones modelo sobre el régimen de la insolvencia en que se regulen determinadas cuestiones internacionales, como las relativas a la jurisdicción, el acceso a los tribunales extranjeros y el reconocimiento de los procedimientos extranjeros, de un modo que no impida la preparación de una convención¹. El segundo tema, relacionado con la responsabilidad de los directores de una empresa en casos de preinsolvencia, se aborda en el documento A/CN.9/WG.V/WP.104.

4. Conforme a la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo en su 40º período de sesiones de que, como hipótesis de trabajo, cabría revisar y ampliar la Guía para la incorporación de la Ley Modelo al derecho interno (A/CN.9/738, párr. 13), en los documentos A/CN.9/WG.V/WP.95 y Add.1, A/CN.9/WG.V/WP.99, A/CN.9/WG.V/WP.103 y Add.1 y A/CN.9/WG.V/WP.105, así como en los informes del Grupo de Trabajo sobre sus períodos de sesiones 39º, 40º y 41º (A/CN.9/715, 738 y 742, respectivamente), figuran propuestas para la revisión de la Guía.

5. La presente nota está basada en esos documentos y contiene otros proyectos de revisión preparados a partir de las deliberaciones sostenidas y las decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo en su 41º período de sesiones. El lector podrá comprender más los cambios introducidos en la Guía consultando la versión publicada de ese documento y los documentos A/CN.9/WG.V/WP.103 y Add.1.

6. En la presente nota no se incluyen los párrafos de la versión publicada de la Guía que no se han revisado o que no contienen texto revisado, salvo en los casos estrictamente necesarios. Para facilitar la consulta, se mantienen los números de párrafo de la versión publicada a fin de indicar cómo se ha reordenado el texto y qué adiciones se han realizado. Por lo tanto, la numeración de los párrafos en la presente nota no es necesariamente secuencial. En los casos en que se ha añadido un nuevo párrafo, este lleva el número del párrafo inmediatamente anterior, seguido de una letra. Se han incluido todos los encabezamientos del texto publicado y se han indicado los números de párrafo correspondientes entre corchetes en el encabezamiento para indicar el contenido y facilitar la comparación con el texto publicado.

7. No se repiten las notas de pie de página de la versión publicada de la Guía que se mantienen sin cambios (si bien los caracteres que las indican siguen figurando en el texto); sin embargo, como la ubicación de algunas notas ha cambiado, se indica dónde figurarían con una nota entre corchetes. Se ha incluido el texto de las notas nuevas y el de las modificadas. También se han omitido las secciones de la Guía tituladas “Examen en la Comisión o en el Grupo de Trabajo”, en que se enumeran los documentos pertinentes, si bien se incluirán en la versión final y se actualizarán para reflejar tanto las deliberaciones originales como las actuales.

Grupos de empresas

8. En el 45º período de sesiones de la Comisión, celebrado en 2012, se planteó la duda de si en el mandato del Grupo de Trabajo estaba incluida la cuestión del centro de los principales intereses en el contexto de los grupos de empresas. Se señaló que,

¹ Véase la propuesta conexas de la Unión Internacional de Abogados, relativa a la posibilidad de preparar una convención, a la que se hace referencia en A/CN.9/686, párrs. 127 a 130.

si bien en el informe del 40º período de sesiones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/738, párr. 37) figuraba lo siguiente en relación con ese asunto: “y, en particular, en relación con el concepto de centro de los principales intereses de un grupo de empresas, se sugirió que, una vez que el Grupo de Trabajo hubiera llegado a un acuerdo sobre los factores importantes para determinar el centro de los principales intereses de un deudor individual, cabría la posibilidad de estudiar con mayor detenimiento la cuestión de los grupos de empresas y, en particular, si procedería aplicar esos factores en el contexto de un grupo de empresas”, no se indicaba allí si el Grupo de Trabajo había aceptado esa sugerencia.

9. El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que en el informe de su 41º período de sesiones (A/CN.9/742, párr. 46) se indica lo siguiente: “Se recordó que el Grupo de Trabajo había convenido en que la revisión de la Guía se centrara en los deudores individuales a los que se aplicaba la Ley Modelo y que la cuestión del trato de los grupos de empresas en procedimientos de insolvencia transfronteriza fuera abordada una vez que se hubiera concluido esa labor”. La Comisión no hizo referencia a ese informe.

10. Otra duda expresada en el 45º período de sesiones de la Comisión fue si el mandato actual del Grupo de Trabajo V abarcaba cuestiones relacionadas con el centro de los principales intereses en relación con los grupos de empresas. El Grupo de Trabajo recordará que el mandato actual está basado en una propuesta de los Estados Unidos, mencionada en el párrafo 3 *supra*; en el mandato figura expresamente la frase “descrita en A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.1, párrafo 8)”. Las referencias incluidas en esa propuesta a cuestiones de insolvencia transfronteriza que afectan a los grupos de empresas están comprendidas en la segunda parte del mandato aprobado por la Comisión, a saber, “y, posiblemente, elaborar una ley modelo o disposiciones modelo sobre el régimen de la insolvencia en que se regulen determinadas cuestiones internacionales, como las relativas a la jurisdicción, el acceso a los tribunales extranjeros y el reconocimiento de los procedimientos extranjeros”.

11. A efectos de disipar toda ambigüedad que pueda existir en torno a esas dos cuestiones, el Grupo de Trabajo tal vez desee aclarar sus puntos de vista y formular una recomendación a la Comisión respecto de a) si su mandato actual abarca cuestiones relativas al centro de los principales intereses en relación con los grupos de empresas, y b) el orden en que se propone abordar los diversos elementos de su actual mandato.

GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNO Y LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA

I. FINALIDAD Y ORIGEN DE LA LEY MODELO

A. Finalidad de la Ley Modelo [párrs. 1 a 3A]

3. Suprimase la palabra “interfaz” que está entre corchetes y reténgase la expresión “marco de cooperación”. En el inciso a), insértese la siguiente nota con respecto a la expresión “Estado promulgante”: “El ‘Estado promulgante’ es el Estado que ha promulgado legislación basada en la Ley Modelo. A menos que se disponga de otro modo, esa expresión se utiliza en la Guía para hacer referencia al Estado que reciba una solicitud en virtud de la Ley Modelo”.

3A. Para los países ya habituados a tener que resolver numerosos casos de insolvencia transfronteriza y los que deseen prepararse como es debido para la eventualidad cada vez más probable de que esos casos proliferen, la Ley Modelo es un punto de referencia esencial en lo que respecta a elaborar un marco efectivo de cooperación transfronteriza.

B. Origen de la Ley Modelo [párrs. 13, 18 y 19]

C. Labor preparatoria y adopción [párrs. 4 a 8]

5. Modifíquese la nota de pie de página de la siguiente manera: [nota 3] El primero fue el Coloquio CNUDMI/INSOL sobre la insolvencia transfronteriza (Viena, 17 a 19 de abril de 1994) (el informe del Coloquio figura en el documento A/CN.9/398 y en http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_insolvency.html; las actas del Coloquio, en *International Insolvency Review, Special Conference Issue, vol. 4, 1995*, y las observaciones de la Comisión relativas al Coloquio, en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo noveno período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/49/17)*, párrs. 215 a 222). El segundo fue el Coloquio Judicial CNUDMI/INSOL sobre la insolvencia transfronteriza que se celebró en Toronto los días 22 y 23 de marzo de 1995 con la finalidad de recabar el parecer de los magistrados en la materia (el informe del Coloquio figura en el documento A/CN.9/413 y en http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_insolvency.html, y las observaciones de la Comisión al respecto, en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/50/17)*, párrs. 382 a 393).

6. Modifíquese la nota de pie de página de la siguiente manera: [nota 5] Los informes del Grupo de Trabajo figuran en los siguientes documentos: 18º período de sesiones (Viena, 30 de octubre a 10 de noviembre de 1995), documento A/CN.9/419 y Corr.1; 19º período de sesiones (Nueva York, 1 a 12 de abril de 1996), documento A/CN.9/422; 20º período de sesiones (Viena, 7 a 18 de octubre de 1996), documento A/CN.9/433, y 21º período de sesiones (Nueva York, 20 a 31 de enero de 1997), documento A/CN.9/435; todos los documentos figuran en <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/sessions.html>.

7. Modifíquese la nota de pie de página de la siguiente manera: [nota 6] El segundo Coloquio judicial multinacional CNUDMI/INSOL sobre la insolvencia

transfronteriza se celebró en Nueva Orleans los días 22 y 23 de marzo de 1997. Se encontrará una reseña de ese Coloquio en el informe de la Comisión sobre la labor de su 30º período de sesiones (Viena, 12 a 30 de mayo de 1997) (*Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/52/17)*, párrs. 17 a 22), y el informe del Coloquio figura en <http://www.uncitral.org/pdf/english/news/SecondJC.pdf>.

II. FINALIDAD DE LA GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNO Y LA INTERPRETACIÓN [párrs. 9 y 10]

9. Modifíquese la tercera oración de la siguiente manera: “Esa información también podría ayudar a los Estados a determinar las disposiciones que, llegado el caso, deberían adaptarse para abordar la situación interna del Estado interesado”.

III. LA LEY MODELO COMO VEHÍCULO DE ARMONIZACIÓN DEL DERECHO [Introducción, párr. 11]

A. *Flexibilidad de la ley modelo* [párr. 12]

B. *Integración de la Ley Modelo en el derecho interno existente* [párrs. 20 y 21 y 49]

IV. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA LEY MODELO [Introducción, párr. 49A]

A. *Acceso* [párrs. 49B a D y 37]

49B. En la segunda oración, sustitúyase la frase “al representante de la insolvencia del Estado promulgante” por “a la persona o el órgano que administra la reorganización o liquidación con arreglo a las leyes del Estado promulgante” (llamado “representante de la insolvencia”) y a continuación insértese la siguiente nota de pie de página: “Se utiliza esta terminología para compatibilizar el texto con el de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia, en que se explica que el “representante de la insolvencia” es la persona o el órgano, inclusive a título provisional, autorizado, en procedimientos de insolvencia, a administrar la reorganización o la liquidación de la masa de la insolvencia”: Introducción, párr. 12 v)”.

Modifíquese la tercera oración de la siguiente manera: “El representante extranjero tiene los siguientes derechos: de acceso directo a los tribunales del Estado promulgante (artículo 9); a solicitar la apertura de un procedimiento en el Estado promulgante con arreglo a las condiciones aplicables en dicho Estado (artículo 11), y a solicitar el reconocimiento del procedimiento extranjero para el cual se le ha nombrado (artículo 15). Tras el reconocimiento, el representante extranjero está facultado para participar en todo procedimiento que se haya abierto en el Estado promulgante sobre asuntos de insolvencia con arreglo a la legislación de dicho Estado (artículo 12); para entablar una acción en el Estado promulgante a fin de anular o de otro modo dejar sin efecto todo acto perjudicial para los acreedores (artículo 23), y para intervenir en todo procedimiento local en el que el deudor sea parte (artículo 24)”.

B. Reconocimiento [párrs. 37A a F]

37A. En la tercera oración, después de las palabras “sobre las características del procedimiento extranjero”, añádase la frase “(es decir, de que el procedimiento extranjero es, entre otras cosas, un procedimiento colectivo² para los fines de la liquidación o la reorganización bajo el control o la supervisión del tribunal)”.

37B. En la primera oración, sustitúyase la frase “que otorgara el reconocimiento” por la frase “en que se procura obtener el reconocimiento” después del término “Estado”. En la cuarta oración, añádanse las palabras “la excepción” antes de las palabras “se interprete”.

37C. En la primera oración, insértese la expresión “ya sea” antes de la palabra “como”. Al final de la segunda oración, insértese la frase “(véanse los respectivos párrs. ...)”. En la tercera oración, sustitúyase “ese procedimiento” por “el procedimiento principal”.

37E. Al final del párrafo, añádanse las palabras “(párrafo 4 del artículo 17)”.

37F. En la segunda oración, después de la palabra “además” añádase la expresión “, como se indicó anteriormente,”.

C. Medidas otorgables [párrs. 37G y H y 32 a 33A]

32. En la tercera oración, suprimase el término “equitativa”.

*D. Cooperación y coordinación [párrs. 33B a G]**Cooperación*

33B. Después de la segunda oración, insértense las oraciones siguientes: “La cooperación no depende del reconocimiento y, por lo tanto, puede tener lugar en una etapa inicial y antes de que se formule la solicitud de reconocimiento. Dado que los artículos del capítulo IV se aplican a las cuestiones que se mencionan en el artículo 1, se puede obtener cooperación no solo con respecto a los pedidos de asistencia presentados en el Estado promulgante, sino también a las solicitudes de asistencia al Estado promulgante en otra parte (véase también el artículo 5). Además, la cooperación no se limita a los procedimientos extranjeros en el sentido del inciso a) del artículo 2, que los habilitaría para el reconocimiento de conformidad con el artículo 17 (es decir, independientemente de que sean principales o no principales), por lo cual podrá obtenerse cooperación con respecto a procedimientos iniciados sobre la base de la presencia de bienes”.

Coordinación de procedimientos paralelos

33E. Insértese la expresión “en el Estado promulgante” antes de las palabras “(artículo 28)” y la expresión “en ese Estado” antes de la frase “no significa”.

² Con respecto a lo que constituye un procedimiento colectivo, véanse los párrs. [...] *infra*.

V. OBSERVACIONES A CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS

Preámbulo [párrs. 54 y 55]

Utilización del término “insolvencia” [párrs. 51 a 53 y 56]

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES - ARTÍCULOS 1 A 8

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Párrafo 1 [párrs. 57 y 59]

Párrafo 2 (Regímenes especiales de la insolvencia) [párrs. 60 a 65]

60 a 64. [...]

65. En las palabras que figuran entre paréntesis, sustitúyase “una ley” por “la ley”.

Personas naturales o no comerciantes [párr. 66]

Artículo 2. Definiciones

Incisos a) a d) [párrs. 67 a 68A]

68. [No se aplica en español.]

68A. [...]

Inciso a) - Procedimiento extranjero [párrs. 71 y 23 a 23A bis]

23A. [No se aplica en español.]

23A bis. En los párrafos siguientes se examinan diversas características exigidas a un “procedimiento extranjero” con arreglo al artículo 2. Si bien se examinan por separado, esas características son acumulativas, y el inciso a) del artículo 2 debería considerarse en su conjunto.

i) El procedimiento colectivo³ [párrs. 23B y C, 24 y 24A]

23B. Para que puedan otorgarse medidas cautelares en un procedimiento conforme a la Ley Modelo, deberá tratarse de un procedimiento colectivo, ya que la Ley Modelo tiene por objeto servir de instrumento para llegar a una solución coordinada y global para todas las partes interesadas en el procedimiento de insolvencia. La Ley Modelo no debe entenderse como un mero mecanismo de cobro para un determinado acreedor o grupo de acreedores que puedan haber entablado un procedimiento en otro Estado con el fin de cobrar sus créditos. Tampoco se pretende que sea un instrumento encaminado a acumular bienes en un procedimiento de liquidación⁴ o de rehabilitación que no prevea también disposiciones para atender a las reclamaciones de los acreedores. La Ley Modelo puede ser un instrumento apropiado para cierta clase de acciones que tengan fines de reglamentación, por

³ **Nota para el Grupo de Trabajo:** Los párrafos 23B y C se han revisado sobre la base del texto propuesto en el 41º período de sesiones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/742, párr. 28) y de las deliberaciones sostenidas y las conclusiones extraídas en ese período de sesiones (A/CN.9/742, párrs. 30 y 31).

⁴ La liquidación es un procedimiento por el cual se pone fin a la existencia de una empresa y de sus negocios.

ejemplo, la administración de entidades sujetas a reglamentación pública como las compañías de seguros o las empresas de corretaje, siempre y cuando el procedimiento sea colectivo en el sentido en que se emplea ese término en la Ley Modelo. Para que un procedimiento sea colectivo, también debe reunir los demás elementos de la definición, entre ellos, que tenga como fin la liquidación o la reorganización (véanse los párrs. 24F y G *infra*).

23C. Al evaluar si un determinado procedimiento es colectivo a efectos de la Ley Modelo, una de las consideraciones fundamentales es determinar si en el procedimiento se tienen en cuenta prácticamente todos los bienes y las deudas del deudor, sin perjuicio de las prioridades y excepciones legislativas del país, ni de la exclusión de determinados derechos de los acreedores garantizados en su ordenamiento jurídico. No se puede considerar que un procedimiento no es colectivo únicamente por el hecho de que no afecte a los derechos de una clase de acreedores. Un ejemplo es el procedimiento de insolvencia en que se excluyen los bienes gravados de la masa de la insolvencia, de tal manera que no les afecte la apertura del procedimiento y se permita a los acreedores garantizados hacer valer sus derechos al margen del régimen de la insolvencia (véase la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia, segunda parte, capítulo II, párrs. 7 a 9). Otra manera de tratar a los acreedores en un procedimiento colectivo a efectos del artículo 2 es otorgar a los que se vean perjudicados por el procedimiento el derecho (aunque no necesariamente la obligación) de presentar sus créditos con miras a que se adopte una determinación y de cobrar una parte equitativa en la distribución que se haga, o a la satisfacción de esos créditos, de participar en el procedimiento y de que este se les notifique a fin de facilitar su participación. La Guía Legislativa se extiende detalladamente sobre los derechos de los acreedores, incluido el de participar en el procedimiento (segunda parte, capítulo III, párrs. 75 a 112).

ii) El procedimiento seguido con arreglo a una norma relativa a la insolvencia [párr. 24B]

iii) El procedimiento sujeto al control o a la supervisión de un tribunal extranjero [párrs. 24C a E]

iv) A los efectos de su reorganización o de su liquidación [párrs. 24F y G]

24G. En la primera oración, suprimase la frase “, incluidos los procedimientos definidos en la Guía Legislativa como agilizados (véase el párr. 24D)” y, al final de esa oración insértese la siguiente nota de pie de página: “Por supuesto, esos arreglos contractuales seguirían siendo ejecutables al margen de la Ley Modelo sin necesidad de reconocimiento; nada de lo dispuesto en la Ley Modelo ni en la Guía para su incorporación al derecho interno tiene por objeto restringir la posibilidad de ejecutarlos”.

El procedimiento de índole provisional [párrs. 69 y 70]

Inciso b) - el procedimiento extranjero principal [párrs. 31 a 31C]

31. En la segunda oración, después de mencionarse el Convenio de la Unión Europea relativo a los procedimientos de insolvencia, insértense las palabras “(el Convenio Europeo)”.

Inciso c) - el procedimiento extranjero no principal [párr. 73]

73. [No se aplica en español.]

Inciso d) - representante extranjero [párr. 73A]

73A. En el inciso d) se reconoce que el representante extranjero puede ser una persona autorizada a administrar el procedimiento extranjero, lo que abarca tratar de obtener el reconocimiento del procedimiento, medidas cautelares y cooperación en otro país, o simplemente una persona autorizada, en especial, a representar el procedimiento. En la Ley Modelo no se especifica que el representante extranjero deba ser autorizado por el tribunal (con arreglo al inciso e) del artículo 2) y la definición es así lo suficientemente amplia como para abarcar los nombramientos que pueda hacer un organismo especial que no sea un tribunal. También están comprendidos los nombramientos provisionales (véanse los párrs. 69 y 70 *supra*). A efectos de la Ley Modelo, es suficiente el hecho de que se haya nombrado al representante extranjero para que actúe en el procedimiento extranjero, ya sea como administrador o como representante, o ambas cosas; en el artículo 15 se exige o bien una copia certificada de la decisión por la que se nombra al representante, o un certificado en que conste el nombramiento u otra prueba aceptable de este. La definición del inciso d) es lo suficientemente amplia como para abarcar a los deudores que sigan en posesión de los negocios tras la apertura del procedimiento de insolvencia.

Inciso e) [párr. 74]

74. Al final del párrafo, suprimanse las palabras “y la Perspectiva Judicial”.

Inciso f) [párrs. 75 a 75B]

75B. Al final del párrafo, suprimase la oración que figura entre corchetes.

Artículo 3. Obligaciones internacionales del Estado [párrs. 76 a 78]

78. [No se aplica en español.]

Artículo 4. [Tribunal o autoridad competente]1 [párrs. 79 a 83]

Artículo 5. Autorización dada a [indíquese la denominación de la persona o del órgano que se encargue de administrar la reorganización o la liquidación con arreglo al derecho interno de este Estado] para actuar en un Estado extranjero [párrs. 84 y 85]

84. Modifíquese la última frase del párrafo de la siguiente manera: “aun cuando conservar el artículo 5 serviría para enunciar sin ambages esa autorización y ayudaría a los tribunales extranjeros y demás personas que invocaran la ley”.

Artículo 6. Excepción de orden público [párrs. 86 a 89]

Artículo 7. Asistencia adicional en virtud de alguna otra norma [párr. 90]

Artículo 8. Interpretación [párrs. 91 y 92]

91. Modifíquese la segunda oración de la siguiente manera: “Más recientemente, se ha reconocido la conveniencia de incluir una disposición de esa índole también en textos de derecho uniforme no convencional como el de una ley modelo, en razón

del interés que tendrá el Estado promulgante en que se dé a su régimen una interpretación armónica”.

CAPÍTULO II. ACCESO DE LOS REPRESENTANTES Y ACREEDORES EXTRANJEROS A LOS TRIBUNALES DEL ESTADO - ARTÍCULOS 9 A 14

Artículo 9. Derecho de acceso directo [párr. 93]

Artículo 10. Jurisdicción limitada [párrs. 94 a 96]

96. [No se aplica en español.]

Artículo 11. Solicitud del representante extranjero de que se abra un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia] [párrs. 97 a 99]

98. En la primera oración, suprimase la expresión “(‘legitimación procesal activa’)” y, después de la expresión “legitimidad procesal”, añádase la siguiente nota de pie de página: “Llamada también ‘legitimación procesal’, ‘legitimación activa’, o ‘legitimación’.”

Artículo 12. Participación de un representante extranjero en un procedimiento abierto con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia] [párrs. 100 a 102]

100. Suprimase el término “procesal” después del término “legitimidad” y la expresión “(‘legitimación procesal activa’)” y, después del término “legitimidad”, hágase remisión a la nota del párrafo 98.

101. Modifíquese el final del párrafo de la siguiente manera: “la suerte de cualquiera de ellas”.

102. Al final del párrafo, añádase la frase “(véanse los párrs. 169 y 172 *infra*)”.

Artículo 13. Acceso de los acreedores extranjeros a un procedimiento abierto con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia] [párrs. 103 a 105]

Artículo 14. Notificación a los acreedores en el extranjero de un procedimiento abierto con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia] [párrs. 106 a 111]

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO EXTRANJERO Y MEDIDAS OTORGABLES

Artículo 15. Solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero

Artículo 15 en su conjunto [párrs. 112 a 118]

Párrafo 4 [párr. 119]

119. Modifíquese la segunda oración de la siguiente manera: “De ser compatible con la práctica del foro, esa discrecionalidad puede facilitar la adopción de una decisión acerca de la solicitud a la mayor brevedad posible, conforme a lo previsto

en el párrafo 3 del artículo 17, siempre y cuando el tribunal esté en condiciones de examinar la solicitud sin disponer de la traducción de los documentos”⁵.

Notificación [párrs. 120 y 121]

120. [La primera modificación no se aplica en español.] En la tercera oración, sustitúyase la frase “que ello justifica que no se requiera” por la frase “que, en consecuencia, no se requiere”. En la cuarta oración, sustitúyase la expresión “Conforme a este parecer” por la expresión “En esas circunstancias” y la palabra “ocasionaría” por las palabras “podría ocasionar”.

Artículo 16. Presunciones relativas al reconocimiento [párr. 122]

Párrafo 1 [párrs. 122A y 122B]

122B. Debe promoverse la inclusión de esa información en la orden del tribunal que abre el procedimiento extranjero para facilitar la tarea de reconocimiento en los casos pertinentes, si bien, como se observa más adelante, esas órdenes o decisiones no son vinculantes para el tribunal del Estado promulgante que recibe la solicitud, que ha de cerciorarse por sí mismo de que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 (analizados más detenidamente en los párrafos 124B y C *infra*). Es conveniente que el tribunal iniciador se limite a decidir acerca del centro de los principales intereses del deudor únicamente cuando haya de determinar su propia competencia. Debería evitarse que lo hiciera con miras a influir en las decisiones del tribunal receptor.

Párrafo 2 [párr. 123]

Párrafo 3 [párrs. 123A a G, 123I y 123K a M]

123A. En la penúltima oración, sustitúyase la frase “es el centro de los principales intereses del deudor” por la frase “era el centro de los principales intereses del deudor”.

123B. Al comienzo de la segunda oración, sustitúyase la expresión “En la mayoría de los casos” por la expresión “Con frecuencia”.

123C. Sin embargo, cuando un representante extranjero solicita el reconocimiento de un procedimiento extranjero como procedimiento principal y parece haber una distinción entre el domicilio oficial del deudor y el presunto centro de sus principales intereses, la parte que alegue que el centro de los principales intereses no es el domicilio oficial deberá probar [convencer al tribunal con respecto a]⁶ la ubicación de este. El tribunal del Estado promulgante deberá determinar por sí mismo la ubicación del centro de los principales intereses del deudor.

⁵ **Nota para el Grupo de Trabajo.** La duda que se plantea en el párrafo 119 es si el tribunal necesita la traducción de los documentos, o puede proceder sin una traducción porque los documentos son comprensibles para él, no si los “entiende”; los documentos pueden estar escritos en el idioma del foro, pero no ser comprensibles de todos modos.

⁶ **Nota para el Grupo de Trabajo.** El artículo 16 3) hace referencia expresamente a la prueba en contrario a fin de satisfacer la presunción. No obstante, se ha sugerido que el término “prueba” utilizado en el párrafo 123C es demasiado fuerte y que sería preferible decir “convencer al tribunal”. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar esa cuestión.

*Centro de los principales intereses⁷ [párrs. 123D a E]**Primera versión⁸*

123D. La previsibilidad y la transparencia del centro de los principales intereses del deudor puede revestir una gran importancia económica para los acreedores. Los acreedores que hacen negocios con el deudor pueden tener en cuenta la jurisdicción ante la cual, en caso de entablarse un procedimiento de insolvencia, deberían con toda probabilidad hacer valer sus reclamaciones, y calcular el riesgo que entrañaría la concesión de crédito en virtud del régimen de la insolvencia que probablemente resultara aplicable. Al hacer esa evaluación, los terceros podrían dejarse influir por información de dominio público y por lo que se desprende del trato habitual con el deudor. Eso podría abarcar, por ejemplo, detalles revelados públicamente por el deudor, declaraciones hechas en material de comercialización e información contenida en contratos y acuerdos.

123E. El concepto de centro de los principales intereses es básico en el Reglamento de la Comunidad Europea. La Ley Modelo también otorga más importancia al procedimiento entablado en el lugar en que se encuentra y prevé que en él se dicten medidas cautelares automáticas y más inmediatas. Los atributos esenciales del centro de los principales intereses del deudor se corresponden con los atributos que permitirán a quienes hagan negocios con el deudor (especialmente a los acreedores) averiguar el lugar en que este podría abrir el procedimiento de insolvencia. Tal como se ha señalado, en la Ley Modelo se establece una presunción de que el lugar al que corresponden esos atributos es el lugar en que la empresa está inscrita. Sin embargo, en realidad, la ubicación del centro de los principales intereses puede no coincidir con el lugar de inscripción. Así pues, es importante tener en cuenta los factores que, de por sí, indican que el centro de los principales intereses del deudor está en determinado lugar, y que deberían consultarse si existieran pruebas en contrario de la presunción prevista en el párrafo 3) del artículo 16.

Segunda versión

123D. El concepto de centro de los principales intereses del deudor es fundamental para el funcionamiento de la Ley Modelo. Esta asigna más importancia al procedimiento entablado en el lugar en que se encuentra y también prevé que en él se dicten medidas cautelares automáticas y más inmediatas. Ese concepto también es básico en el Reglamento de la Comunidad Europea. La Ley Modelo establece la

⁷ **Nota para el Grupo de Trabajo.** Se han suprimido las versiones previas de los párrafos 123D y E y en su lugar se ha incorporado el texto aprobado en el 41º período de sesiones del Grupo de Trabajo que figura en el documento A/CN.9/742, párr. 52, con algunos cambios editoriales y revisado ligeramente por la Secretaría. Se somete a consideración una segunda versión de esos párrafos.

⁸ **Nota para el Grupo de Trabajo.** El texto respaldado por el Grupo de Trabajo V en su 41º período de sesiones (A/CN.9/742, párr. 52) se refiere a las expectativas de los acreedores y el lugar en que estos podrían esperar que se abriera el procedimiento. Sin embargo, como el primer factor que ha de considerarse para determinar el centro de los principales intereses es la posibilidad de que los acreedores lo averigüen, el proyecto de texto se ha adaptado a ese concepto. Al analizar la formulación de esos párrafos, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la relación entre las “expectativas”, por una parte, y la “posibilidad de averiguar”, por la otra.

presunción de que el centro de los principales intereses está situado en el lugar en que está inscrita la empresa. Sin embargo, en realidad, su ubicación puede no coincidir siempre con el lugar de inscripción, y la Ley Modelo prevé la posibilidad de impugnar la presunción si estuviera en otro lugar. Si el centro de los principales intereses del deudor no está situado en el lugar de inscripción, deberá determinarse teniendo en cuenta otros factores que indiquen a quienes hacen negocios con el deudor (especialmente a los acreedores) dónde está. Así pues, es importante tener en cuenta los factores que, de por sí, pueden indicar que el centro de los principales intereses del deudor está situado en determinado Estado.

Factores pertinentes para determinar el centro de los principales intereses⁹
[párrs. 123F y G e I]

123F. En la mayoría de los casos, los factores principales que se exponen a continuación, considerados globalmente, tenderán a indicar si el lugar en que se abrió el procedimiento es aquel en que se encuentra el centro de los principales intereses del deudor. Los factores que han de tenerse en cuenta son: a) si el lugar es fácil de averiguar para los [acreedores] [terceros]; b) si se trata del lugar en que se encuentra la [administración] [administración central o las operaciones] del deudor, [y c) si es el lugar en que se encuentran los principales bienes u operaciones del deudor]¹⁰.

123G. Con frecuencia esos factores coincidirán en señalar que el centro de los principales intereses se encuentra en una determinada jurisdicción. En algunos casos, sin embargo, puede haber conflictos entre los factores, lo que hará necesario que se estudien más detenidamente los hechos. Si bien no existe ningún factor que sea sistemáticamente determinante, y cada uno de los factores puede ser más o menos pertinente o importante para dar una idea de la verdadera ubicación del centro de los principales intereses del deudor, de cualquier modo el tribunal puede tener que dar más o menos peso a determinado factor, según las circunstancias del caso. Así pues, se trata de establecer los hechos, y el tribunal analizará diversos factores para determinar con toda la objetividad posible dónde se encuentra el centro de los principales intereses de un deudor concreto. En todas las situaciones, el proceso de búsqueda es integral y tiene por objeto determinar que el lugar del procedimiento extranjero se corresponde efectivamente con el del centro de los principales intereses del deudor.

⁹ **Nota para el Grupo de Trabajo.** Se ha suprimido la versión previa de los párrafos 123F y 123G y se ha preparado un nuevo proyecto sobre la base del texto propuesto en el 41º período de sesiones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/742, párr. 52) y las deliberaciones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/742, párr. 53). El párrafo 123G está basado en la segunda mitad del texto del párrafo 123F propuesto en el documento A/CN.9/742, párr. 52.

¹⁰ **Nota para el Grupo de Trabajo.** Se hicieron diversas sugerencias con respecto a los tres factores determinantes del centro de los principales intereses (A/CN.9/742, párrs. 52 y 53). En general se apoyaron las sugerencias relativas a las ideas expresadas por los factores a) y b) (independientemente de su formulación). Sin embargo, se expresaron dos opiniones contrarias con respecto a la ubicación de los principales bienes. La opinión contraria a que se incluyera ese factor era de que podía indicar varias ubicaciones diferentes y crear incertidumbre respecto de lo que constituían los “principales” bienes (párr. 53). La opinión a favor de que se incluyera era de que en la liquidación podía no haber ya una administración central, y la ubicación de los principales bienes del deudor podía ser un indicador conveniente. En general, el Grupo de Trabajo no apoyó la supresión de ese factor y se ha dejado entre corchetes con miras a seguirlo examinando.

[123I.¹¹ Cuando los factores mencionados no se prestan para determinar fácilmente el centro de los principales intereses del deudor, pueden considerarse otros elementos relativos a los negocios del deudor, entre ellos los siguientes: la ubicación de la contabilidad y los registros de su empresa; la ubicación en que se organizó o autorizó la financiación o se administraba el sistema de gestión del efectivo; el lugar en que se encontraba el banco principal del deudor; el lugar en que estaban sus empleados; el lugar en que se definía la política comercial; el ámbito jurisdiccional donde estaba vigente la legislación aplicable, o la legislación aplicable a los principales contratos de la empresa; el lugar desde el que se gestionaba la política de compras y ventas, el personal, las cuentas a pagar y los sistemas informáticos; el lugar en que se organizaban los contratos (de suministro); el lugar desde el que se dirigía la reorganización de la empresa; la jurisdicción cuya legislación regiría la mayoría de los litigios; el lugar en que el deudor era sometido a supervisión o reglamentación, y el lugar en que se preparaban y auditaban las cuentas y cuya legislación era la aplicable a esas operaciones.]

*Traslado del centro de los principales intereses*¹² [párrs. 123K a M]

123K. En algunos casos el deudor ha cambiado el lugar de inscripción (o su residencia habitual si se trata de una persona física) en fecha muy próxima a la apertura del procedimiento de insolvencia, incluso entre la fecha de la solicitud de apertura y la apertura efectiva del procedimiento. Algunas veces el traslado tuvo por objeto dar acceso al deudor a un proceso de insolvencia, por ejemplo, de reorganización, que atendiera más a sus necesidades que el que le ofrecían las leyes de la jurisdicción en que se encontraba su domicilio anterior, lo que puede considerarse una razón legítima para cambiar el país de inscripción de la empresa. En esos casos, el tribunal receptor no tendrá mayores problemas para determinar el centro de los principales intereses teniendo en cuenta el lugar de inscripción.

123L. En otros casos, el traslado del lugar de inscripción (o de la residencia habitual) puede considerarse meramente oportunista y tener por objeto frustrar las expectativas legítimas de los acreedores y los terceros, o haberse hecho aprovechando información confidencial o por motivos subjetivos. Por regla general, siempre que se compruebe que se ha cambiado el lugar de inscripción en fecha muy próxima a la apertura del procedimiento extranjero, puede ser conveniente que el tribunal receptor, para decidir si reconoce o no el procedimiento, considere los

¹¹ **Nota para el Grupo de Trabajo.** El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que examinara los párrafos 123E a I con miras a determinar el material que podría ser conveniente conservar. En el párrafo 123I se ha añadido una nueva oración introductoria. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si deben conservarse todos los factores, o si la lista podría abreviarse suprimiendo, por ejemplo, el ámbito jurisdiccional donde estaba vigente la legislación aplicable, o la legislación aplicable a los principales contratos de la empresa; el lugar desde el que se dirigía la reorganización de la empresa, y la jurisdicción cuya legislación regiría la mayoría de los litigios. Lo que anteriormente era el texto del párrafo 123H se ha añadido al final del párrafo 123D.

¹² **Nota para el Grupo de Trabajo.** El párrafo 123J, que trata del abuso del proceso, se ha trasladado al artículo 17 porque en general se refiere al abuso del proceso como motivo para denegar el reconocimiento, no solo en relación con el centro de los principales intereses y, especialmente, con el traslado de este muy cerca de la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia. Se ha suprimido la versión previa del párrafo 123K y se han preparado nuevos párrafos 123K a L en cumplimiento de la solicitud formulada por el Grupo de Trabajo en su 41º período de sesiones (A/CN.9/742, párr. 56).

factores mencionados en el párrafo [...] *supra* más cuidadosamente y tenga en cuenta las circunstancias del deudor de manera más amplia. En particular, la condición de que los terceros puedan averiguar fácilmente cuál es el centro de los principales intereses será más difícil de cumplir si el traslado de este ha tenido lugar en una fecha próxima a la apertura del procedimiento. Si el solicitante declara falsamente que el centro de los principales intereses se encuentra en determinado Estado, el tribunal receptor puede determinar que se ha incurrido en abuso deliberado del proceso. La Ley Modelo no impide que el tribunal receptor aplique las leyes o las normas procesales internas para hacer frente a cualquier clase de abuso del proceso.

123M. No es probable que un deudor pueda cambiar el lugar de inscripción de su empresa (o su residencia habitual) tras la apertura del procedimiento de insolvencia, ya que en muchos casos el régimen de la insolvencia contiene disposiciones especiales para impedirlo. En cualquier caso, si eso ocurriera, no afectaría a la adopción de una decisión sobre el centro de los principales intereses a efectos de la Ley Modelo, ya que la fecha que se ha de tener en cuenta para determinarlo es la de la apertura del procedimiento extranjero (véanse los párrs. 128A a C *infra*).

Artículo 17. Resolución de reconocimiento de un procedimiento extranjero [párrs. 124 a 124C, 126 a 128C, 123J, 125 y 129 a 132]

Párrafo 1 [párrs. 124 a 124C]

124B. Modifíquese la primera oración de la siguiente manera: “Para adoptar la decisión sobre el reconocimiento, el tribunal receptor puede tener en cuenta debidamente todas las decisiones y órdenes del tribunal iniciador y toda [prueba] [información]¹³ presentada ante el tribunal que abra el procedimiento”.

124C. Modifíquese la primera oración de la siguiente manera: “En consecuencia, el reconocimiento de un procedimiento extranjero se facilitaría si el tribunal iniciador mencionara en sus órdenes toda [prueba] [información] que permitiera decidir al tribunal receptor si el procedimiento es un procedimiento extranjero en el sentido del artículo 2”.

Párrafo 2 [párrs. 126 a 128]

Momento de determinar el centro de los principales intereses [párrs. 128A a 128C]

128A. [No se aplica en español.]

128C. Modifíquese la primera oración de la siguiente manera: “Con respecto a la fecha en que ha de determinarse el centro de los principales intereses del deudor, habida cuenta de las pruebas que han de presentarse junto con la solicitud de reconocimiento, de conformidad con el artículo 15, y de la importancia asignada a la resolución por la que se declara abierto el procedimiento extranjero y se nombra al representante extranjero, la fecha de apertura de ese procedimiento es la fecha

¹³ **Nota para el Grupo de Trabajo.** Con respecto al párrafo 122B, el Grupo de Trabajo convino en referirse únicamente a incluir “información” en las órdenes del tribunal iniciador. Tal vez desee considerar la posibilidad de que en los párrafos 124B y C también se haga referencia únicamente a la “información”.

adecuada”¹⁴. Suprímase la segunda oración e insértese el siguiente texto: “Ese criterio es compatible con el adoptado en el Reglamento de la Comisión Europea, en que la fecha en que se determina el centro de los principales intereses es la de la apertura del procedimiento de insolvencia”.

Abuso del proceso [párr. 123J]¹⁵

123J. Una cuestión que ha surgido en lo que respecta a la solicitud de reconocimiento es si el tribunal debe estar facultado para tener en cuenta que se está cometiendo un abuso del proceso como justificación para denegar el reconocimiento. Ninguna disposición de la Ley Modelo de la CNUDMI sugiere por sí misma que cuando se solicite un reconocimiento deban tenerse en cuenta circunstancias externas. La Ley Modelo prevé que la respuesta a la solicitud venga determinada por los criterios concretos que se derivan de las definiciones de “procedimiento extranjero”, “procedimiento extranjero principal” y “procedimiento extranjero no principal”. Dado que lo que constituye abuso del proceso depende de la legislación o las normas procesales internas, la Ley Modelo no impide expresamente que el tribunal receptor aplique la legislación interna, en particular las normas procesales, para hacer frente al presunto abuso del proceso. No obstante, debe tenerse en cuenta el propósito más amplio de la Ley Modelo, a saber, el de promover la cooperación internacional como medio de optimizar los resultados para todos los interesados, establecido en el artículo 1, así como los orígenes internacionales de la Ley Modelo, y la necesidad de promover su aplicación uniforme, establecida en el artículo 8. Los tribunales que consideren la posibilidad de aplicar las leyes y normas procesales internas podrían recordar también que la excepción de orden público prevista en el artículo 6 (véanse los párrs. 86 a 89 *supra*) ha de interpretarse en sentido estricto e invocarse únicamente cuando la adopción de una medida con arreglo a la Ley Modelo fuera manifiestamente contraria al orden público de un Estado. Como regla general, el artículo 6 muy raramente podría servir de base para denegar el reconocimiento, si bien podría servir de base para limitar las medidas otorgadas.

Párrafo 3 [párr. 125]

125. Al final de la segunda oración, suprímase la frase “, por lo que el tribunal deberá estar en condiciones de poder concluir el proceso de reconocimiento con la brevedad requerida”.

¹⁴ En algunos regímenes de la insolvencia, los efectos de la apertura se retrotraen a la fecha de la solicitud de apertura, o la fecha de la solicitud pasa a ser la de la apertura automáticamente. En ambos casos, conviene tener en cuenta la fecha de la apertura para la determinación del centro de los principales intereses, ya que la Ley Modelo solo se ocupa del procedimiento extranjero existente y del momento en que se inició.

¹⁵ **Nota para el Grupo de Trabajo.** El párrafo 123J, que anteriormente estaba comprendido en las observaciones relativas al artículo 16, se ha trasladado al artículo 17, por entenderse que el abuso del proceso no se limita exclusivamente a la cuestión de determinar el centro de los principales intereses y puede estar relacionado con la decisión de reconocimiento en general.

Párrafo 4 [párrs. 129 a 131]

130. Al final de la primera oración, añádase la siguiente frase: “o si ha cambiado la situación con respecto al mandato del representante extranjero o se le ha puesto término”.

131. [No se aplica en español.]

*Notificación de la decisión de reconocimiento de un procedimiento extranjero [párr. 132]**Artículo 18. Información subsiguiente**Inciso a) [párr. 133]*

133. Modifíquense las oraciones cuarta y quinta de la siguiente manera: “En el inciso a) se tiene en cuenta que es frecuente que se produzcan modificaciones técnicas en la situación del procedimiento o en el mandato del representante extranjero, pero que solo algunas de esas modificaciones afectarían a la decisión de otorgar medidas cautelares o de reconocer el procedimiento; en consecuencia, la disposición se limita a exigir que se informe de todo cambio “importante”. Es particularmente relevante que se mantenga informado al tribunal de todo cambio que se produzca cuando su decisión de reconocimiento se refiera a un “procedimiento de índole provisional” o a un representante extranjero “nombrado a título provisional” (véanse los incisos a) y d) del artículo 2).

Inciso b) [párr. 134]

134. [No se aplica en español.]

*Artículo 19. Medidas otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero**Párrafo 1 [párrs. 135 a 137]*

135. [No se aplica en español.]

136. [No se aplica en español.]

137. [No se aplica en español.]

Párrafo 2 [párr. 138]

138. En la segunda oración, sustitúyase la palabra “sería” por la palabra “es”.

Párrafo 3 [párr. 139]

139. En la primera oración, suprimanse las palabras “esas medidas” antes de “quedarán sin efecto”.

Párrafo 4 [párr. 140]

140. En la primera oración, sustitúyase la frase “de estarse siguiendo un procedimiento extranjero principal” por la frase “en caso de haber un procedimiento extranjero principal en curso”.

Artículo 20. Efectos del reconocimiento de un procedimiento extranjero principal
[Introducción, párrs. 141 a 147]

144. En la primera oración, suprimase la palabra “también”.

145. Modifíquese la penúltima oración de la siguiente manera: “Por ejemplo, si el arbitraje no se celebra ni en el Estado promulgante ni en el Estado en que tiene lugar el procedimiento principal, tal vez será difícil paralizar el procedimiento arbitral.” [La segunda modificación no se aplica en español].

146. En la primera oración, después de la palabra “abarcar”, añádase “, además de,” y suprimase la expresión “sino también” antes de “las medidas de ejecución”.

Párrafo 2 [párrs. 148 a 150]

149. Modifíquese la cuarta oración de la siguiente manera: “Si se da a los tribunales esa facultad, ciertos ordenamientos normalmente exigirían que se precisaran los motivos por los que el tribunal podría modificar o dar por terminados los efectos automáticos del reconocimiento en virtud del párrafo 1 del artículo 20”.

Párrafo 3 [párrs. 151 y 152]

151. En la primera oración, después de la expresión “como resultado” añádase las palabras “de la aplicación”.

152. Modifíquese la segunda oración de la siguiente manera: “No obstante, ese párrafo puede ser útil en esos Estados debido a la posibilidad de que la interrupción del plazo de prescripción se rija, en virtud de alguna norma concerniente al conflicto de leyes, por el derecho interno de un Estado que no sea el promulgante; ese párrafo daría, además, a los acreedores extranjeros la seguridad de que sus créditos no se verían perjudicados en el Estado promulgante”.

Párrafo 4 [párr. 153]

153. En la primera oración, sustitúyase la frase “El párrafo 4 se limita a aclarar” por la frase “En el párrafo 4 se aclara”.

Artículo 21. Medidas otorgables a partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero
[Introducción, párrs. 154 a 156]

154. En la tercera oración, después de “se enuncian”, añádase “las medidas cautelares que se otorgan con más frecuencia en un procedimiento de insolvencia,”.

156. [No se aplica en español.]

Párrafo 2 [párr. 157]

Párrafo 3 [párrs. 158 a 160]

158. Al final de la penúltima oración, añádase las palabras “no principal” después de la palabra “procedimiento”. [La modificación de la última oración no se aplica en español].

160. Modifíquese el comienzo de la oración de la siguiente manera: “La idea que subyace en el párrafo 3 del artículo 21 también se refleja en el artículo 19.”.

Artículo 22. Protección de los acreedores y de otras personas interesadas
[párrs. 161 a 164]

162. Al final de la primera oración, sustitúyanse las palabras “artículos 19 o 21” por las palabras “artículos 19 y 21”. En la segunda oración, sustitúyase la frase “dosificar mejor esas medidas” por la frase “dosificar esas medidas de manera apropiada”.

163. En la última oración, sustitúyanse las palabras “esa definición” por las palabras “un texto apropiado”. [La segunda modificación no se aplica en español.]

164. En la primera oración, sustitúyase la palabra “informar” por la palabra “notificar”.

Artículo 23. Acciones de impugnación de actos perjudiciales para los acreedores
[párrs. 165 y 166, 166A y 167]

165. En la penúltima oración, suprimase el término “procesal” y hágase remisión a la nota del párrafo 98.

166. En la primera oración, después del término “legitimado”, hágase remisión a la nota del párrafo 98 y suprimase el texto que figura entre paréntesis. Modifíquese la segunda oración de la siguiente manera: “La disposición ha sido redactada en términos restrictivos, ya que no crea ningún derecho sustantivo respecto de esas acciones ni ofrece una solución ante un posible conflicto de leyes; la Ley Modelo no aborda la cuestión del derecho de un representante extranjero a interponer una acción de esa índole en el Estado promulgante con arreglo al derecho interno del Estado en que tiene lugar el procedimiento extranjero.” En la tercera oración, sustitúyanse las palabras “de esta disposición” por las palabras “del artículo 17”.

167. En la primera oración, suprimase el término “procesal” y hágase remisión a la nota del párrafo 98.

Artículo 24. Intervención de un representante extranjero en procedimientos que se sigan en este Estado [párrs. 168 a 172]

170. En la primera oración, suprimase el término “procesal” y hágase remisión a la nota del párrafo 98.

**CAPÍTULO IV. COOPERACIÓN CON TRIBUNALES Y REPRESENTANTES
EXTRANJEROS** [párrs. 38 y 39 y 173 a 178]

Artículo 25. Cooperación y comunicación directa entre un tribunal de este Estado y los tribunales o representantes extranjeros [párr. 179]

Artículo 26. Cooperación y comunicación directa entre [indíquese la denominación de la persona o del órgano encargado de administrar una reorganización o liquidación con arreglo a la ley del foro] *y los tribunales o representantes extranjeros* [párr. 180]

Artículo 27. Formas de cooperación [párrs. 181 a 183A]

183. En la primera oración, sustitúyase la palabra “posibilidad” por la palabra “oportunidad”.

183A. Al final del párrafo, hágase remisión a la Guía de Prácticas de la CNUDMI sobre Cooperación en la Insolvencia Transfronteriza.

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS PARALELOS

Artículo 28. Apertura de un procedimiento con arreglo a [identifíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia] tras el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal [párrs. 184 a 187]

185. En la cuarta oración, sustitúyase la frase “El artículo 28 opta por la solución menos restrictiva” por la frase “En el artículo 28 se escogió la solución menos restrictiva”.

187A. En los casos en que con arreglo a la ley del foro el deudor debe ser insolvente a efectos de abrir un procedimiento de insolvencia, la Ley Modelo establece la presunción rebatible de que el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal constituye prueba suficiente de que el deudor es insolvente a esos efectos (artículo 31) (véanse los párrs. 194 a 197).

Artículo 29. Coordinación de un procedimiento seguido con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia] y un procedimiento extranjero [párrs. 188 a 191]

Artículo 30. Coordinación de varios procedimientos extranjeros [párrs. 192 y 193]

Artículo 31. Presunción de insolvencia basada en el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal [párrs. 194 a 197]

Artículo 32. Regla de pago para procedimientos paralelos [párrs. 198 a 200]

VI. ASISTENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CNUDMI [párrs. 201 y 202]

B. Información sobre la interpretación de normas legales basadas en la Ley Modelo

201. Modifíquense las direcciones de correo electrónico y de la página web de la siguiente manera: correo electrónico: uncitral@uncitral.org; página web: www.uncitral.org.

202. Modifíquense las oraciones primera y segunda de la siguiente manera: La Ley Modelo se ha incluido en el sistema de información en materia de Jurisprudencia de los Tribunales sobre textos de la CNUDMI (CLOUT), que se utiliza para la recopilación y difusión de información sobre jurisprudencia relativa a las convenciones y leyes modelo elaboradas por la Comisión. La finalidad de ese sistema es promover el conocimiento de esos textos legislativos a nivel internacional y facilitar su interpretación y aplicación uniformes.

C. Nota de la Secretaría sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 42º período de sesiones

(A/CN.9/WG.V/WP.108)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
Introducción.	1-5
I. Obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia	6-51
A. Introducción.	6-19
B. Determinación de las partes en que recaen las obligaciones.	20-23
C. Cuándo nacen las obligaciones: el período cercano a la insolvencia	24-27
D. La naturaleza de las obligaciones.	28-33
E. El criterio que ha de cumplirse.	34-37
F. Ejecución de las obligaciones de los directores respecto a la apertura de un procedimiento de insolvencia	38-51
1. Defensas.	38-40
2. Recursos.	41-47
3. Partes que pueden entablar una acción	48-50
4. Financiación del procedimiento	51
Proyectos de recomendación 1 a 10	
II. Cuestiones relativas a los directores de empresas pertenecientes a un grupo	52-60
A. Observaciones generales	52-59
B. Cuestiones que se deben examinar.	60
III. Cuestiones transfronterizas	61

Introducción

1. En su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión tuvo a su disposición varias propuestas para una labor futura sobre el régimen de la insolvencia (documentos A/CN.9/WG.V/WP.93 y Add.1 a 6 y documento A/CN.9/582/Add.6). Esas propuestas habían sido examinadas por el Grupo de Trabajo V en su 38º período de sesiones (véanse los párrs. 99 a 107 del documento A/CN.9/691), ocasión en que se recomendaron a la Comisión posibles temas de estudio (véase el párr. 104 del documento A/CN.9/691). Con posterioridad a ese período de sesiones del Grupo de Trabajo V, se presentó otro documento (A/CN.9/709) con material complementario de la propuesta de Suiza que figuraba en el documento A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5.

2. Después de sus deliberaciones, la Comisión apoyó la recomendación del Grupo de Trabajo V que figuraba en el párrafo 104 del documento A/CN.9/691 de que se emprendieran actividades sobre dos temas relacionados con la insolvencia, que tenían importancia en la actualidad y en los que una mayor armonización de las reglamentaciones de los distintos Estados aportaría mayor certeza y previsibilidad.
3. El objeto de la presente nota es el segundo tema, propuesto por el Reino Unido (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.4), la Federación Internacional de Profesionales en materia de Insolvencia (INSOL International) (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.3) y el International Insolvency Institute (A/CN.9/582/Add.6), relativo a la responsabilidad y las obligaciones de los directores y ejecutivos de una empresa en situación de insolvencia o previa a la insolvencia¹. Dadas las inquietudes planteadas durante el extenso debate la Comisión convino en que, en relación con este tema, se trataría únicamente la responsabilidad y las obligaciones que nacieran en el contexto de la insolvencia sin pretender abarcar aspectos de la responsabilidad penal ni cuestiones estrictamente del ámbito de la legislación sobre sociedades.
4. El examen de este tema comenzó en el 39º período de sesiones del Grupo de Trabajo (celebrado en diciembre de 2010 en Viena) y continuó en los períodos de sesiones 40º y 41º de ese Grupo (celebrados en octubre y noviembre de 2011 en Viena y del 30 de abril al 4 de mayo de 2012 en Nueva York). Las deliberaciones y conclusiones del Grupo de Trabajo figuran en los informes de esos períodos de sesiones (documentos A/CN.9/715, A/CN.9/738 y A/CN.9/742, respectivamente).
5. De conformidad con la hipótesis de trabajo adoptada por el Grupo de Trabajo en su 41º período de sesiones (párr. 74 del documento A/CN.9/742) de que la labor formaría parte de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia la presente nota incluye un borrador de comentario (párrs. 6 a 51 de la parte I) y las recomendaciones 1 a 10, así como también observaciones generales sobre las obligaciones de los directores en el contexto de un grupo de empresas (parte II) y cuestiones transfronterizas (parte III). El material que figura a continuación se basa en los documentos A/CN.9/WG.V/WP.96, 100 y 104, así como en las decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo en sus períodos de sesiones 39º, 40º y 41º. Los párrafos del proyecto de comentario contenidos en el documento A/CN.9/WG.V/WP.104 que no han sido reformados o que no incluyen un texto reformado no figuran en la presente nota y están indicados de la siguiente manera: - “6. [...]”. Para facilitar la consulta se ha conservado el número de párrafo empleado en el documento A/CN.9/WG.V/WP.104. Cuando se ha agregado un nuevo párrafo este toma el número del párrafo inmediatamente anterior con el agregado de una letra. El lector comprenderá mejor los cambios propuestos en el presente documento si los compara con el texto del documento A/CN.9/WG.V/WP.104.

¹ El primer tema, relativo al centro de los principales intereses y cuestiones conexas se examina en el documento A/CN.9/WG.V/WP.107.

I. Obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia

A. Introducción

6. [...]

7. [...]

8. Al final de la primera oración, agregar la siguiente frase: “en el período anterior a la iniciación del procedimiento de insolvencia”. En la tercera oración suprimir la frase que comienza con las palabras “Con todo” y termina con la palabra “procedimientos” y reemplazarla por la siguiente frase: “No está claramente establecido el carácter ni el alcance de las obligaciones que puedan tener los directores en un período en que la empresa pueda tener problemas financieros sin ser todavía insolvente, pero”.

9. Al final de la primera oración, agregar la frase “que serán decisivos para la supervivencia de la empresa, con los consiguientes beneficios para sus dueños, acreedores, clientes, empleados y demás interesados”. En la tercera oración, agregar la palabra “debidamente” antes de la palabra “partes”. Agregar una cuarta y una quinta oración: “En algunas legislaciones esas partes interesadas serán la propia sociedad y sus accionistas. En otras legislaciones puede tratarse de una comunidad de intereses más amplia que incluya a los acreedores”. Corregir la oración final de la siguiente forma: “Un director temeroso de las posibles repercusiones financieras de la adopción de decisiones difíciles en esas circunstancias puede cerrar prematuramente una empresa en lugar de intentar resolver las dificultades, puede incurrir en comportamientos indebidos, como la disposición impropia de los bienes o el patrimonio, o también puede sentirse tentado a renunciar, lo que a menudo aumenta las dificultades que tiene la sociedad”.

9A. Corregir la primera oración de la siguiente forma: “No es fácil lograr un equilibrio entre los diferentes intereses y motivaciones de las partes interesadas, los cuales pueden convertirse en una fuente de conflicto”. En la segunda oración corregir la primera parte de la siguiente forma: “Por ejemplo, los accionistas de la empresa, que generalmente tienen pocas posibilidades de participar en una distribución que se realice en el procedimiento de insolvencia, están interesados en mejorar su propia posición tratando de negociar una salida de la insolvencia”, y la última frase de la siguiente forma: “y no dejan nada a los accionistas”.

10. En la cuarta oración, reemplazar las palabras “por las operaciones” con las palabras “por las operaciones comerciales”. En la última oración corregir las palabras finales de la siguiente forma: “no actuaron de manera oportuna”.

11. En la última oración, corregir la parte central de la siguiente forma: “para que se actúe cuanto antes recurriendo con prontitud a las negociaciones de reestructuración o a la reorganización, e impedir que los directores externalicen”.

12. En la tercera oración, agregar las palabras “las obligaciones” y en la tercera y cuarta oración, reemplazar la palabra “directivos” por “directores”.

13. Agregar una segunda oración, a saber: “Una norma por la que se presuma la mala gestión basándose solamente en el hecho de la dificultad financiera suele

provocar la renuncia de directores que por lo demás son idóneos y competentes y se pierde la oportunidad de reorganizar la sociedad y devolverle la rentabilidad”. Al final de la cuarta oración, agregar las siguientes palabras: “y tiene más probabilidades de lograr un equilibrio entre los derechos y las expectativas legítimas de todas las partes interesadas, distinguiendo los casos de mala conducta de los casos que entrañan mala suerte o las consecuencias de factores exógenos”.

14. En la segunda oración, reemplazar las palabras “y para” por “y podrían optar por”. En la tercera oración, reemplazar “los tribunales tienden a” por “los tribunales han tendido a”. En la penúltima oración, agregar la palabra “todos” antes de “los acreedores”.

15. En la penúltima oración, agregar las palabras “en la actualidad” antes de la frase “pueden no encontrar una respuesta”. Al comienzo de la última oración, agregar la expresión “Sin embargo,”.

16. En la primera oración, agregar la frase “como se ha señalado *supra*” después de los dos puntos.

17. [...]

18. En la primera oración, reemplazar las palabras “tratar de salvaguardar” por “salvaguardar” y después de la palabra “desalentar” agregar las palabras “conductas indebidas y”. En la última oración, agregar la palabra “confusas” después de “poco prácticas,” y al final de la oración, agregar la siguiente frase “y agravar la dificultad financiera que pretenden solucionar”.

19. En la última oración, reemplazar las palabras “ser ejecutables” por “serían ejecutables”.

B. Determinación de las partes en que recaen las obligaciones

20. [...]

21. [...]

22. En la segunda oración, poner entre corchetes las palabras “o” y “o debería adoptar”.

23. [suprimido]

C. Cuándo nacen las obligaciones: el período cercano a la insolvencia

24. Combinar las primeras dos oraciones de la siguiente manera: “Esta [parte] se centra en las obligaciones que pueden nacer en algún momento anterior a la apertura del procedimiento de insolvencia y que son ejecutables una vez iniciado ese procedimiento y como consecuencia de su apertura, con aplicación retroactiva de forma similar a las disposiciones de anulación (véase el debate en la segunda parte, capítulo II, párrs. 148 a 150 y 152). Corregir la oración que comienza con la palabra “Aunque” de la siguiente manera: “Aunque el concepto puede ser impreciso, pretende describir un período en que existe tal deterioro de la estabilidad financiera de la empresa que, si no se subsana y no se adoptan medidas correctivas, la insolvencia es inminente (vale decir, cuando la empresa deja de estar, en general, en

condiciones de pagar sus deudas a su vencimiento (recomendación 15 a) de la Guía Legislativa)) o es inevitable”. Agréguese las siguientes dos oraciones: “Determinar con exactitud el momento en que nacen esas obligaciones es una cuestión fundamental para los directores que tratan de adoptar decisiones en forma oportuna y compatible con esas obligaciones. Además, sin un punto de referencia claro sería difícil para los directores predecir con exactitud qué momento del período anterior al comienzo del procedimiento de insolvencia el tribunal habría de tener en cuenta al entender en una acción por incumplimiento de esas obligaciones”.

25. Corregir la primera oración de la siguiente forma: “Hay diversos criterios para determinar el momento en que pueden nacer las obligaciones de los directores en el período anterior al comienzo del procedimiento de insolvencia”. En la segunda oración, reemplazar la palabra “crea” por la palabra “aporta”. Al final de párrafo, agregar la siguiente frase “por lo que respecta a alentar a los directores a actuar con prontitud”.

26. En la cuarta oración, sustituir las palabras “sirven de base” por “son la base”. Corregir la última oración de la siguiente forma: “El motivo de la imposición de obligaciones a los directores sobre la base de esos criterios de solvencia es alentarlos a que intenten evitar la insolvencia o, cuando esta sea inevitable, a que adopten medidas para reducir al mínimo su alcance, por ejemplo solicitando, cuando corresponda, la apertura oficial del procedimiento de insolvencia”.

27. Agregar una nueva cuarta oración: “Esencialmente esto requiere evaluar la actuación del director en función del conocimiento que un director razonable habría o debería haber tenido en las circunstancias del caso”.

D. La naturaleza de las obligaciones

28. Al final del párrafo, corregir las palabras después del paréntesis de la siguiente forma: “y la anulación en el procedimiento de insolvencia de medidas adoptadas por los directores en la proximidad de una insolvencia, incluso operaciones comerciales”.

a) Obligación de iniciar un procedimiento de insolvencia

29. [...]

b) Responsabilidad civil

30. [...]

31. Después de la frase “reducir al mínimo las pérdidas de la empresa”, agregar “(incluso las de los accionistas)”.

32. [...]

a) [...]

b) Agregar la siguiente oración al final del apartado: “Puede que los directores deban dedicar más tiempo y atención a los asuntos de la empresa en ese momento del que necesitarían dedicarle cuando la sociedad es próspera”.

c) a f) [...]

g) Corregir la mención de “el entorno” por “y las cuestiones ambientales”. Al final del apartado, reemplazar “como consecuencia” por “que puede ser consecuencia”;

h) En la primera oración, agregar “se protejan los activos de la empresa y que esta” después de las palabras “los directores pueden velar por que”. Agregar una segunda oración: “En determinadas circunstancias, no todos los activos requerirán protección; por ejemplo los que estén asegurados por un valor inferior al de su garantía son gravosos, carentes de valor y difíciles de convertir en efectivo (véase la segunda parte, capítulo II, párr. 88)”. Al final del párrafo, agregar la siguiente oración: “Los directores con un gran paquete accionario o que representen a importantes accionistas no se pueden considerar desinteresados ni imparciales, y en el período cercano a la insolvencia deberían tener particular cuidado cuando voten sobre operaciones;”.

i) [...]

Responsabilidad mancomunada y solidaria

32A. Usualmente los directores son responsables por incumplimiento de sus obligaciones en forma mancomunada y solidaria, aunque según algunas legislaciones los tribunales pueden ordenar que uno de los directores asuma el total de la responsabilidad o que uno de ellos contribuya en mayor medida cuando, por ejemplo, se haya determinado que la culpabilidad por el daño causado no es equitativa. Partir de una responsabilidad mancomunada y solidaria puede favorecer el carácter disuasivo de la imposición de obligaciones, ya que los directores tendrán interés en supervisar la conducta de sus pares para evitar la responsabilidad por su conducta.

32B. Los directores pueden adoptar medidas para evitar o reducir su responsabilidad por decisiones que posteriormente se cuestionen. Para ello, puede ser necesario que cumplan con determinados requisitos formales, como por ejemplo dejar constancia de su oposición en las actas de la reunión; entregar un escrito en que expresen su desacuerdo al secretario de la reunión antes de que esta se levante; o entregar o enviar su oposición por escrito inmediatamente después de levantada la reunión al domicilio social de la empresa. Se puede considerar que los directores que han estado ausentes en una reunión en que se adoptaron determinadas decisiones han prestado su consentimiento a menos que cumplan con el procedimiento establecido, como por ejemplo adoptar las medidas necesarias para dejar sentada su oposición dentro de determinados plazo después de conocida la decisión en cuestión.

32C. Se puede disminuir la responsabilidad mediante un seguro o el uso de resarcimientos. En determinadas legislaciones es posible, cuando se ha presentado una denuncia contra un director, negociar un acuerdo con el representante de la insolvencia; este es el criterio habitual en algunas jurisdicciones.

c) Anulación de operaciones

33. En la tercera oración, agregar las palabras “en ciertas legislaciones pueden considerarse ilícitos” después de la palabra “además,” y suprimir las palabras “pueden pasar a ser ilícitos” después de la palabra “los directores”. Al principio de

la última oración, agregar las palabras “Según esas disposiciones,” antes de la expresión “la responsabilidad”.

E. El criterio que ha de cumplirse

34. Cambiar las palabras “se suele juzgar” por “se juzga”.

35. [...]

36. En la primera oración, después de la palabra “deuda” agregar “o realizar la operación”. En la segunda oración, reemplazar las palabras “exista una situación de insolvencia” por “la empresa es insolvente”. En la cuarta oración, la corrección no se aplica al español.

37. En la tercera oración, que comienza con “Entre los ejemplos de comportamientos”, después de la palabra “responsabilidad” agregar “de conformidad con esas legislaciones”. Al comienzo de la última oración, agregar la siguiente frase: “En algunos ordenamientos jurídicos que adoptan ese criterio,”.

F. Ejecución de las obligaciones de los directores respecto a la apertura de un procedimiento de insolvencia

1. Defensas

38. La corrección no se aplica al texto español.

39. En la segunda oración, reemplazar las palabras “esta defensa” por “esto como defensa”.

40. [...]

2. Recursos

41. Al comienzo de la primera oración, suprimir las palabras “En numerosos regímenes se prevén” y reemplazar “recursos, también en el derecho civil” por “recursos se prevén en el derecho civil”. Agregar la penúltima frase siguiente: “Evidentemente, los daños y perjuicios no tienen carácter punitivo”.

a) Daños y perjuicios e indemnización

42. Corregir la tercera oración de la siguiente forma: “Como se señaló *supra*, generalmente la responsabilidad de los miembros del directorio suele ser solidaria, pero en algunos casos puede corresponder a determinados directores”.

43. Cambiar las últimas palabras del párrafo de la siguiente manera: “prevén también que se otorgue una indemnización”.

44. Corregir las primeras dos oraciones de la siguiente forma: “Cuando los directores son considerados responsables puede especificarse que la cantidad recuperada engrosará la masa de la insolvencia dado que la principal justificación para demandar a los directores es recuperar en forma de indemnización para la masa de la insolvencia parte del valor que se ha perdido por sus actos”. En la segunda oración, reemplazar las palabras “existe una hipoteca de empresa” por “la empresa tiene una hipoteca”. En la tercera oración, reemplazar las palabras “tales casos” por

“apoyo de tal criterio”. Al final del párrafo, agregar la siguiente oración: “Sin embargo, cuando la legislación permita que los acreedores demanden a los directores (véase *infra*), estaría justificado sugerir que la indemnización se destine, en primer lugar, a cubrir las costas incurridas por el acreedor o los acreedores que iniciaron el procedimiento y para satisfacer sus demandas o modificar la prelación de sus créditos²”.

45. Cambiar la última palabra de forma que quede la siguiente frase: “el incumplimiento de sus obligaciones”.

b) Inhabilitación

46. [...]

47. [...]

3. Partes que pueden entablar una acción

48. Al final de la primera oración, agregar la siguiente frase: “vale decir, antes o después de iniciado el procedimiento de insolvencia”. Corregir la segunda oración de la siguiente manera: “Podrían ser aplicables consideraciones similares a las aplicables al ejercicio de las facultades de anulación, examinadas en la recomendación 87 (véase al segunda parte, capítulo II, párrs. 192 a 195)”.

49. En la primera oración, después de las palabras “contra el director”, suprimir la frase “, por ejemplo, para obtener la anulación de una operación particular o” y reemplazarla por “para obtener”.

49A. Si bien una importante razón de imponer obligaciones a los directores en el período cercano a la insolvencia es la protección de los intereses de los acreedores no todos los ordenamientos jurídicos permiten a estos demandar a un director por incumplimiento de sus obligaciones. Algunos regímenes reconocen en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando el representante de la insolvencia no adopta ninguna medida, a los acreedores y a veces a los accionistas el derecho de interponer una acción subrogatoria (véase la segunda parte, capítulo II, párrs. 192 a 195). Según otras legislaciones, un acreedor solo puede actuar contra los directores con el consentimiento de la mayoría de los acreedores o del comité de acreedores, o bien los acreedores pueden solicitar a su representante, al comité o al tribunal que interponga esa acción, ya que no tienen un derecho independiente a interponerla.

49B. Cuando se considere conveniente que la ley permita a los acreedores demandar a los directores puede marcarse una distinción entre los acreedores cuya deuda nació en el período cercano a la insolvencia como resultado directo de la conducta en examen y los acreedores cuya deuda fuera anterior a ese período. Los primeros, además del derecho de iniciar procedimientos en beneficio de la masa de la insolvencia, pueden tener el derecho personal de reclamar daños y perjuicios contra el director sobre la base de que la conducta en cuestión ocurrió en el período problemático y exacerbó las dificultades financieras del deudor. En algunas legislaciones ese derecho individual queda limitado a los casos en que el mal

² **Nota al Grupo de Trabajo.** Tal vez el Grupo de Trabajo desee considerar si en el comentario debería tratarse la cuestión de que el director tenga o no la capacidad de pagar la indemnización ordenada y las consecuencias de la falta de esa capacidad.

comportamiento en cuestión fue dirigido a un acreedor determinado. De considerarse conveniente permitir que los acreedores interpongan acciones contra el director las disposiciones del régimen de la insolvencia aplicables a la anulación pueden servir de modelo para el procedimiento que habría que seguir (véase la segunda parte, párrs. 192 a 195). Por ejemplo, la ley puede requerir el consentimiento previo del representante de la insolvencia para asegurar que este tenga conocimiento del propósito de los acreedores y la oportunidad de denegar su autorización, evitando así cualquier perjuicio que ese procedimiento pueda causar a la administración de la masa de la insolvencia.

[49C. Cuando para demandar a un director el acreedor debe contar con el consentimiento del representante de la insolvencia o de los acreedores, pero no lo haya obtenido o le haya sido denegado, la ley puede permitirle solicitar la aprobación del tribunal. El representante de la insolvencia debería tener derecho a ser escuchado en la correspondiente vista judicial para explicar por qué considera que no debería continuarse con las actuaciones. En esa vista el tribunal podría autorizar que se inicie el procedimiento o podría decidir que examinará el fondo del caso. Ese criterio puede reducir la posibilidad de que las diversas partes lleguen a un arreglo. En los casos en que se permite que los acreedores interpongan una demanda de anulación, algunas leyes estipulan que las costas del procedimiento sean a cargo de los acreedores o admiten la imposición de sanciones a los acreedores para desalentar posibles abusos; ese mismo criterio se puede aplicar a las demandas de los acreedores contra los directores³.]

50. Corregir la primera oración de la siguiente forma: “En las normativas que imponen a los directores la obligación de iniciar procedimientos de insolvencia (véase el párr. 29), la propia sociedad, sus accionistas y acreedores pueden tener derecho a una indemnización por daños y perjuicios en caso de incumplimiento de esa obligación”. Al final del párrafo, agregar la siguiente oración: “Es conveniente que el régimen de la insolvencia garantice la coordinación de los procedimientos que puedan iniciar las diferentes partes”.

4. Financiación del procedimiento

51. Corregir la primera oración de la siguiente forma: “Una dificultad que podría surgir en las jurisdicciones en que el representante de la insolvencia esté autorizado a entablar una demanda es la relativa al pago de sus costas en el caso de que la demanda contra el director no prospere. La falta de financiación disponible se cita a menudo como una razón importante de que los casos de demanda por incumplimiento de esas obligaciones sean relativamente escasos. Si bien pueden facilitarse fondos de la masa de la insolvencia cuando existan bienes suficientes para hacerlo, como suele ocurrir con los procedimientos de anulación, los representantes de la insolvencia pueden no estar dispuestos a utilizar esos bienes para entablar una demanda si no hay una probabilidad muy elevada de que esta prospere (véase la segunda parte, capítulo II, párr. 196). Sin embargo, en muchos casos los fondos disponibles en la masa de insolvencia no serán suficientes para

³ **Nota al Grupo de Trabajo.** El presente párrafo se basa en material incluido en la Guía Legislativa con respecto al procedimiento de anulación (concretamente la segunda parte, capítulo II, párr. 193). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si este párrafo se debería incluir aquí o si bastaría hacer una remisión a los párrafos pertinentes de la Guía Legislativa.

demandar a un director, aunque sean muchas las posibilidades de éxito. Encontrar en esas circunstancias un criterio de financiación alternativo puede ofrecer, en determinadas condiciones, un medio efectivo para devolver a la masa los bienes perdidos por actos de los directores, corregir abusos, investigar conductas desleales y promover la buena gobernanza. Puede cederse a un tercero, incluso a los acreedores, la facultad de entablar el procedimiento, o el producto previsto de este si prospera, a cambio de un importe o se puede recurrir a un prestamista para que provea los fondos. Cuando el demandante es una parte distinta del representante de la insolvencia el costo de comenzar esas actuaciones puede recuperarse de la indemnización que se pague. En algunas legislaciones las demandas contra los directores se pueden dirimir mediante negociaciones con los representantes de la insolvencia, evitando la necesidad de financiación. En algunas jurisdicciones esto no es frecuente, mientras que en otras constituye una práctica habitual, y los representantes de la insolvencia suelen “invitar” a los directores a que hagan contribuciones. Como cuestión adicional, sería apropiado considerar también el tribunal en que se pueden entablar esas actuaciones; esta cuestión se ha examinado *supra*, en la segunda parte, capítulo I, párr. 19”.

Proyectos de recomendación 1 a 10

Finalidad de las disposiciones legislativas

Las disposiciones relativas a las obligaciones de [los encargados de adoptar decisiones acerca de la gestión de una empresa] [los directores] que nacen cuando la insolvencia es posible [inminente] o inevitable tienen por finalidad:

- a) proteger los intereses legítimos de los acreedores y demás interesados;
- b) velar por que [los encargados de adoptar decisiones acerca de la gestión de una empresa] [los directores] estén enterados de sus funciones y responsabilidades en esas circunstancias;
- c) proveer recursos apropiados en caso de incumplimiento de esas obligaciones, que podrán hacerse efectivos una vez comenzado el procedimiento de insolvencia.

Los párrafos a) a c) se aplicarán de forma que:

- a) no resulten en perjuicio de la reorganización satisfactoria de la empresa;
- b) no desalienten la participación en la gestión de empresas, especialmente las que experimentan dificultades financieras;
- c) no impidan la aplicación de un discernimiento comercial razonable o que se asuma un riesgo comercial razonable.

Observaciones

1. El párrafo b) ha sido agregado a la cláusula de la finalidad de conformidad con la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo en su 41º período de sesiones (véase el párr. 99 del documento A/CN.9/742) de que se incluyera el objetivo de servir de instrumento para informar a los directores sobre sus funciones y responsabilidades en el período cercano a la insolvencia. La segunda parte del nuevo párrafo c) ha sido agregada para aclarar que las obligaciones solo serán exigibles una vez comenzado

el juicio de insolvencia. Lo que antes era el párrafo c) ha quedado incluido ahora como una segunda oración.

Contenido de las disposiciones legislativas

Recomendación 1 [anteriormente recomendaciones 4 y 6]

La obligación

1 1) [El régimen de la insolvencia] [La ley relativa a la insolvencia] debería especificar que desde el momento a que se hace referencia en la recomendación 2 las personas mencionadas en la recomendación 3 tendrán la obligación de tener debidamente en cuenta los intereses de los acreedores y demás interesados y:

- a) adoptar medidas razonables para evitar la insolvencia;
- b) cuando la insolvencia sea inevitable, reducir al mínimo su alcance.

2) Entre las medidas razonables cabría citar las siguientes: asegurarse de que [estén] [esté] plenamente [informados] [informado] de los asuntos de la empresa; buscar asesoramiento profesional cuando corresponda; [y] velar por que los activos de la empresa estén protegidos; [y no concertar el tipo de operaciones que pueda ser anulable de conformidad con [la segunda parte, capítulo II] [la recomendación 87] ni permitir que la empresa lo haga].

Observaciones

2. Se ha modificado la secuencia de los proyectos de recomendación para centrarse, en primer lugar, en la obligación y luego en el momento en que esta nace y a quién le incumbe su cumplimiento. Sin embargo, uno de los ajustes de redacción que el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar es el empleo de la palabra “director” en la cláusula de la finalidad y en las recomendaciones 1 y 2. Como la parte a quien incumbe la obligación es objeto de una recomendación de fondo (recomendación 3) tal vez en otras recomendaciones corresponda referirse a la persona mencionada en la recomendación 3 o referirse a esa persona en una forma más genérica, como por ejemplo la persona encargada de adoptar decisiones sobre la dirección de la empresa o responsable de su gestión.

3. En su 41º período de sesiones el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que volviera a examinar los proyectos de recomendación 1, 4, 5 y 6 (véase el párrafo 93 del documento A/CN.9/742). El presente proyecto de recomendación 1 combina los textos anteriores de las recomendaciones 4 y 6. El párrafo 1 trata de los elementos de la obligación, mientras que el párrafo 2 contiene ejemplos de lo que constituirían medidas razonables que deben adoptarse de conformidad con el párrafo 1.

4. La referencia al régimen de insolvencia (o a la legislación relativa a la insolvencia) tiene por objeto indicar que la obligación en la recomendación 1 se aplica solo en el marco de esa normativa, y que, si bien el incumplimiento de la obligación debe darse antes de que comience el procedimiento de insolvencia de conformidad con lo enunciado en la recomendación 2, la responsabilidad solo puede ser exigible una vez comenzado ese procedimiento. Si esto no ha quedado suficientemente claro tal vez sea conveniente repetir la segunda parte de la cláusula de finalidad c) en el cuerpo de las recomendaciones.

5. En la segunda parte de la recomendación 1 se exige la adopción de medidas razonables para evitar la insolvencia o para reducir al mínimo su alcance, cuando esta sea inevitable. Esto sugiere que la obligación podría nacer en dos momentos virtualmente diferentes. Sin embargo, en la práctica la distinción entre los dos momentos puede depender de la secuencia de acontecimientos y puede que solo se vea claramente con posterioridad al acontecimiento. Por ejemplo, un suceso catastrófico o una conmoción exógena puede hacer inevitable la insolvencia, sin que hubiera un período en el que se pudieran adoptar medidas correctivas. Por otra parte, puede haber posibilidades de caer en la insolvencia debido a factores externos, como un suceso determinado o una caída momentánea del mercado, pero que no se concreten gracias a una mejora en esos factores externos o porque se adoptaron medidas para evitar las consecuencias.

6. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si la cuestión de la oportunidad es un tema que deba tratarse en la redacción de las recomendaciones (especialmente en las recomendaciones 1 y 2) o si el texto actual es suficiente claro.

Recomendación 2 [anteriormente recomendación 3]

¿Cuándo nacen las obligaciones?

2. [El régimen de la insolvencia] [La ley relativa a la insolvencia] debería especificar que la obligación mencionada en la recomendación 1 nace en el momento en que la persona mencionada en la recomendación 3 supo, o debería razonablemente haber sabido, que la insolvencia era probable [inminente] o inevitable.

Observaciones

7. En el 41º período de sesiones se convino en mantener la recomendación 3 tal como estaba redactada (véase el párr. 82 del documento A/CN.9/742). Sin embargo, se ha expresado una cierta duda de que el texto actual abarque tanto la situación financiera del deudor como una cuestión de hecho (vale decir que la insolvencia era de hecho “probable [inminente] o inevitable” en el momento en cuestión) y el conocimiento que tuviera el director de ese hecho. Con la redacción actual esta cuestión debería estar abarcada por la frase “era probable [inminente] o inevitable” al final del proyecto de recomendación, ya que el conocimiento solo se puede imputar a un hecho o una situación que ya se ha dado. Sin embargo, el Grupo de Trabajo tal vez desee decidir si es necesario agregar una aclaración sobre este punto.

8. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si la cuestión planteada en el párrafo 5 *supra* con respecto a la oportunidad debe mencionarse en la recomendación 2 o si el texto actual es suficientemente flexible para abarcar las distintas posibilidades.

Recomendación 3 [anteriormente recomendación 2]

Partes en que recaen las obligaciones

3. [El régimen de la insolvencia] [La ley relativa a la insolvencia] debería especificar [la persona] en quien recae la obligación, que puede tratarse de cualquier persona que, en virtud de las definiciones del derecho nacional, cumpla la función de un director* [, como por ejemplo un director designado oficialmente o cualquier

otra persona [que ejerza el control *de facto*] [[y que ejerza las funciones] [que asuma las responsabilidades] de un director]].

* Véase en los párrafos 20 a 22 *supra* la explicación de quién puede ser considerado un director.

Observaciones

9. En el 41º período de sesiones se presentaron varias propuestas con respecto a esta recomendación (véanse los párrafos 79 y 80 del documento A/CN.9/742). Existe amplio acuerdo en que debería aplicarse a toda persona que en virtud de las definiciones del derecho nacional cumpla la función de un director. Como ejemplo se propuso (párr. 79) que la recomendación se aplicara a quienes ejercieran libremente funciones de gestión o adoptaran decisiones de gestión, incluso quienes debieran adoptar ese tipo de decisiones pero que no necesariamente lo hicieran. A fin de detallar más detenidamente el tipo de persona que debería incluirse en esta definición se han agregado las palabras entre corchetes y una nota de pie de página que remite a los párrafos pertinentes del comentario.

Recomendación 4 [anteriormente recomendaciones 1, 5 y 7]

Responsabilidad

4 1) [El régimen de la insolvencia] [La ley relativa a la insolvencia] debería especificar que [los intereses de los acreedores se han visto perjudicados] [los acreedores han sufrido pérdidas o perjuicios] como consecuencia del incumplimiento de la obligación en la recomendación 1 [ocurrido en el período mencionado en la recomendación 2], [la persona imbuida de la obligación] [el director] puede ser responsable.

4 2) [El régimen de la insolvencia] [La legislación relativa a la insolvencia] debería estipular que la responsabilidad por incumplimiento de la obligación en la recomendación 1 está limitada a la medida de las pérdidas y los daños que ha causado el incumplimiento.

Observaciones

10. El proyecto de recomendación 4 combina ideas ya reflejadas en los proyectos de recomendación 1 y 5 y el encabezamiento de la recomendación 7, vale decir que cuando se incumpla la obligación de la recomendación 1 y los acreedores sufran pérdidas o daños o sean perjudicados sus intereses puede hacerse responsable a la persona imbuida de la obligación. El resto del anterior proyecto de recomendación 7 (vale decir los párrafos a) a d)) ha quedado incorporado al proyecto de recomendación 6. El párrafo 2 del proyecto de recomendación 4 se refiere a un requisito que antes figuraba en el encabezamiento del proyecto de recomendación 7, de que la responsabilidad sea proporcional al daño causado o, en otras palabras, que la responsabilidad esté limitada a la medida del daño causado por el incumplimiento.

11. En el 41º período de sesiones se sugirió (párr. 77 del documento A/CN.9/742) que en el texto de la antigua recomendación 1 se agregaran las palabras “efectuadas durante el período previo a la apertura del procedimiento de insolvencia” a fin de aclarar que el incumplimiento de la obligación debe ocurrir en el período anterior al

inicio del procedimiento de insolvencia. Como el proyecto de recomendación 1 se remite a la recomendación 2, podría ser conveniente que en el proyecto de recomendación 4 solo se conservara la remisión al proyecto de recomendación 1 y se evitara así la complejidad adicional de repetir la condición de que el incumplimiento sea en un momento determinado.

Recomendación 5 [nueva, reemplaza la recomendación 6]

Elementos de la responsabilidad y excepciones

5. [El régimen de la insolvencia] [La ley relativa a la insolvencia] debería especificar los elementos que habrán de probarse a fin de establecer el incumplimiento de la obligación enunciada en la recomendación 1, y que esta ha provocado [una pérdida o daño a los acreedores] [un perjuicio a los intereses de los acreedores]; a qué parte corresponde la carga de esa prueba; y las posibles excepciones que podrán oponerse a una alegación de incumplimiento de la obligación. Una de las excepciones que se pueden oponer es que [la persona imbuida de la obligación] [el director] ha adoptado medidas razonables del tipo de las mencionadas en el párrafo 2 de la recomendación 1. La ley podrá también establecer presunciones y permitir la inversión de la carga de la prueba para facilitar el curso del procedimiento por incumplimiento de la obligación.

Observaciones

12. En el 41º período de sesiones se expreso preocupación con respecto a la forma en que el proyecto de recomendación 6 había reflejado la cuestión de la prueba del incumplimiento de la obligación enunciada en la recomendación 1 y las posibles excepciones oponibles.

13. El proyecto de recomendación enfoca ahora la realización del procedimiento por incumplimiento de las obligaciones enunciadas en la recomendación 1 de la misma forma en que la recomendación 97 de la Guía Legislativa enfoca la realización del procedimiento de anulación. Vale decir que si bien se señala la necesidad de que la legislación regule cuestiones tales como las excepciones, los elementos que se deben probar, y establezca las presunciones y la carga de la prueba, el proyecto de recomendación deja a la legislación nacional la determinación y especificación de los requisitos exactos.

Recomendación 6 [anteriormente recomendación 7]

Recursos

6. [El régimen de la insolvencia] [La ley relativa a la insolvencia] debería especificar que los recursos oponibles por responsabilidad [podrían] [deberían] incluir el pago completo a la masa de la insolvencia de todo resarcimiento por daños y perjuicios fijado por incumplimiento de la obligación enunciada en la recomendación 1. La falta de pago de la totalidad de esos daños debería impedir que [la persona imbuida de la obligación] [el director] pudiera ejercer ningún derecho o demanda contra la masa de la insolvencia [en el período en que se adeude el pago] [mientras no se haya efectuado el pago en su totalidad].

Observaciones

14. En su 41º período de sesiones el Grupo de Trabajo decidió que el proyecto de recomendación se centrara en los perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación de la recomendación 1 y en la reparación de esos perjuicios. Con la reforma de la recomendación quedó en claro que la indemnización por daños y perjuicios acrecienta la masa de la insolvencia (el proyecto de recomendación 7 deja en claro que la facultad o el derecho de demandar a un director es un activo de la masa). La segunda oración se basa en los párrafos c) y d) del texto anterior de la recomendación 7.

15. El requisito del pago íntegro antes de que un director pueda ejercer una acción de repetición contra la masa tiene por objeto resolver la cuestión de si sería permisible el resarcimiento. Sin embargo, en algunas legislaciones una norma que impida a la persona que tiene la titularidad de la obligación ejercer un derecho o una acción contra la masa de la insolvencia podría crear dificultades, ya que es una disposición estrechamente relacionada con el tema de la propiedad. Por ejemplo, se le podría considerar una denegación del derecho de propiedad del acreedor sobre las acciones judiciales. La intención del proyecto de recomendación 6 es fomentar el pago e impedir que un director responsable de causar perjuicios se beneficie de cualquier distribución con respecto a sus derechos contra la masa de la insolvencia mientras esté pendiente el pago del resarcimiento por daños y perjuicios. En la recomendación se podría aclarar que su intención es postergar el derecho a repetir o el ejercicio de sus derechos contra la masa de la insolvencia hasta tanto no se haya efectuado el pago íntegro de lo adeudado o no se haya cancelado ese derecho. Véase la nota de pie de página del párrafo 44 *supra*, relativa a la capacidad del director de pagar los perjuicios fijados.

Recomendación 7 [anteriormente recomendación 8]**Sustanciación del procedimiento por incumplimiento de la obligación**

7. [El régimen de la insolvencia] [La ley relativa a la insolvencia] debería especificar que la causa de la acción por [el daño causado por] [la pérdida o perjuicio sufrido como resultado del] incumplimiento de la obligación enunciada en la recomendación 1 corresponde a la masa de la insolvencia y el representante de la insolvencia es el principal responsable de iniciar el procedimiento por incumplimiento de dicha obligación. [El régimen de la insolvencia] [La ley relativa a la insolvencia] podrá también permitir a un acreedor o a cualquier otra parte interesada iniciar ese procedimiento con el consentimiento del representante de la insolvencia o, en caso de haberse denegado ese consentimiento, el acreedor o la otra parte interesada podrá solicitar autorización judicial para iniciar dicho procedimiento.

Observaciones

16. El proyecto de recomendación 7 fue corregido de conformidad con la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo en su 41º período de sesiones (véase el párr. 96 del documento A/CN.9/742) de estipular que los acreedores o cualquier otra parte interesada pudiera iniciar el procedimiento por incumplimiento de la obligación enunciada en la recomendación 1. Dado que el término “parte interesada” está definido en el glosario de la Guía Legislativa (véase el párr. 12 dd) de la

introducción), se emplea también en la recomendación revisada para garantizar la inclusión de los accionistas y otras partes pertinentes.

17. Como diferentes jurisdicciones pueden permitir que los acreedores y demás personas interpongan acciones, esa posibilidad puede incluirse en la recomendación como una opción. Ese derecho de interponer una acción debería corresponder a la masa de la insolvencia o ser parte de ella para sentar un principio claro y un destino claro para el pago de cualquier resarcimiento fijado por los daños y perjuicios respecto del incumplimiento (véase el proyecto de recomendación 6).

18. En algunas legislaciones la mayoría de los acreedores y el comité de acreedores deben renunciar al derecho de demandar por incumplimiento a un director antes de que ese derecho se pueda adjudicar a un solo acreedor. Si bien esa posibilidad figura en el comentario (párrs. 49A y B), se agregaría otro nivel de complejidad al proyecto de recomendación si se estableciera a) que la causa de la acción corresponde a la masa de la insolvencia, b) que el representante de la insolvencia tiene el derecho de ejercerla, c) que los acreedores pueden ejercerla con aprobación del representante de la insolvencia (o del tribunal), y d) que un acreedor solo puede ejercerla cuando tenga la aprobación de la mayoría de los acreedores además de la del representante de la insolvencia.

Recomendaciones 8 y 9 [anteriormente recomendaciones 9 y 10]

Financiación de los procedimientos por incumplimiento de la obligación

8. [El régimen de la insolvencia] [La ley relativa a la insolvencia] debería especificar que las costas del procedimiento contra un director se abonarán como gastos de administración de la masa.

9. [El régimen de la insolvencia] [La ley relativa a la insolvencia] podrá prever otras formas de regular la sustanciación y financiación de ese procedimiento.

Observaciones

19. En su 41° período de sesiones el Grupo de Trabajo adoptó el contenido de los anteriores proyectos de recomendación 9 y 10 (véase el párr. 97 del documento A/CN.9/742).

Recomendación 10 [anteriormente recomendación 11]

Medidas adicionales

10. [El régimen de la insolvencia] [La ley relativa a la insolvencia] podrá incluir otras medidas además de los recursos mencionados en la recomendación 6 para desalentar todo comportamiento que pueda dar lugar a la responsabilidad según los dispuesto en la recomendación 4. [Una de esas medidas podría ser restringir [la facultad de la persona que tenga la obligación de desempeñarse como director] [la posibilidad de un director de desempeñarse como tal] por un período de tiempo determinado].

Observaciones

20. En el 41° período de sesiones se expresaron reservas con respecto a la segunda oración del proyecto de recomendación porque podría representar una medida

punitiva y, por lo tanto, ser inapropiada (véase el párr. 98 del documento A/CN.9/742). Como no se logró acuerdo sobre este punto se acordó conservar la segunda oración entre corchetes, a la espera de un examen más profundo.

II. Cuestiones relativas a los directores de empresas pertenecientes a un grupo

A. Observaciones generales

52. En la tercera parte de la Guía Legislativa se señala que un grupo de empresas se suele caracterizar por diversos grados (de altamente centralizado a relativamente independiente) y tipos (vertical y horizontal) de integración y por relaciones complejas entre las empresas del grupo que pueden representar distintos niveles de dominio y de control. Esos factores, junto con la forma en que los grupos tienden a estar regulados por la ley aplicable (vale decir como entidades separadas en oposición a una única empresa) plantean varias cuestiones para los directores de las empresas pertenecientes a un grupo. En el siguiente análisis se examinan dos cuestiones en el contexto de las obligaciones del director de una empresa perteneciente a un grupo. La primera se refiere a la prevalencia del principio de la entidad única y sus consecuencias para el director cuando haya conflicto entre la actuación en interés de la empresa de la que es director y los intereses del grupo al que esta pertenece. La segunda se refiere a la definición de quién puede ser considerado director (véanse los párrs. 20 a 22 *supra*) y la circunstancias en que las otras empresas del grupo pueden estar abarcadas por esa definición, especialmente cuando entra en juego la relación entre la sociedad matriz y las filiales de propiedad total o controladas.

a) Consecuencias de la estructura de un grupo de empresas para las obligaciones del director

53. Generalmente los directores tienen obligaciones respecto de su sociedad y deben actuar en beneficio o en interés de ella. En el contexto del grupo, se debe respetar el principio de la personalidad propia y, en virtud de la mayoría de las legislaciones, se aplican esas mismas obligaciones, independientemente de toda consideración de los intereses del grupo y de la posición que ocupa la sociedad del director en la estructura del grupo. Ese énfasis en los intereses de un miembro del grupo tiene particular importancia cuando la solvencia de ese miembro pueda plantear un problema o se convierte en un problema después de realizada una operación destinada a beneficiar al grupo en su totalidad. Pero en la práctica la estructura del grupo puede llevar a los directores a actuar en beneficio de todo el grupo, viéndose obligados a equilibrar los intereses de su propia empresa contra los objetivos o necesidades económicas del grupo colectivo, que posiblemente sean opuestos. Entre los ejemplos de posibles casos de conflicto se pueden citar que una empresa del grupo realice un préstamo a otra empresa del mismo grupo o salga de garante de un préstamo concedido a otra empresa del grupo por un prestamista externo; que una empresa del grupo concierte un acuerdo con otra empresa del mismo grupo para transferirle su negocio o sus activos o para cederle una oportunidad comercial o para concertar un contrato con esa empresa en términos que no se pueden considerar comercialmente viables; o que una empresa del grupo salga

de garantía cruzada de otras empresas del grupo para ayudarlo a aprovechar mejor sus activos en la financiación de las operaciones del grupo en sí. Esas operaciones pueden ser problemáticas por la relación entre las partes en la operación (es decir, con respecto al dominio y el control) o su posición dentro del grupo (es decir, matriz o filial) y porque el carácter de la operación implica una distribución de beneficios y perjuicios que no se ajusta a lo que generalmente se consideraría comercialmente viable. Sería más fácil, por ejemplo, determinar los beneficios que recibe la empresa matriz al prestarle o realizar otras operaciones con una subsidiaria de propiedad total (operaciones hacia abajo) que lo contrario (operaciones hacia arriba), especialmente cuando la filial no es de propiedad total, o los beneficios resultan de operaciones entre filiales del grupo (operaciones horizontales).

54. Si bien comercialmente puede parecer poco realista exigir que el director de una empresa perteneciente a un grupo ignore la estructura de grupo en que opera su empresa, la dificultad nace con las consideraciones señaladas *supra* sobre la forma de evaluar los beneficios de una operación para las empresas individuales que conforman el grupo cuando dicha operación solo parece resultar sensata desde la perspectiva global del grupo. En algunos casos el beneficio puede ser directo y relativamente fácil de determinar; en otros puede no ser inmediatamente aparente e incluso puede requerir un cierto sacrificio de la empresa individual, aunque más no sea en el corto plazo. Además, la evaluación puede entrañar múltiples factores similares a los señalados en la recomendación 217 (tercera parte), como por ejemplo la relación entre las partes en la operación y el grado de integración entre ellas, la finalidad de la operación, si gracias a la operación las empresas del grupo u otras personas allegadas han obtenido alguna ventaja que normalmente no se otorgaría entre partes no allegadas y si la operación se puede catalogar como hacia arriba, hacia abajo u horizontal.

55. Los tribunales de diferentes jurisdicciones han acordado distintos grados de reconocimiento a la realidad práctica de la forma en que operan los grupos de empresas. Si bien el énfasis sigue recayendo en el director que ejerce sus facultades en beneficio de su propia empresa, en algunas jurisdicciones el director puede, sin embargo, considerar los beneficios comerciales directos o indirectos que tiene para su empresa una determinada operación con otras empresas del grupo y la medida en que la prosperidad o supervivencia de ella depende del bienestar del grupo en sí. Generalmente el mero beneficio colectivo no es justificación suficiente. Además, se puede exigir al director que tome en consideración todo posible perjuicio que pueda sufrir su empresa como resultado de la operación y que tome en consideración la posición de los acreedores no garantizados de su empresa, especialmente cuando la operación en cuestión pueda afectar la solvencia de esa empresa. Esta última consideración es de particular importancia cuando la operación consiste en dar una garantía o una fianza por un préstamo concedido a otra empresa del mismo grupo⁴.

56. Otras jurisdicciones han permitido que el director de una sociedad del grupo actúe en interés de todo el grupo cuando se dan determinadas condiciones, como por ejemplo que el grupo tenga una estructura equilibrada y firmemente establecida; que la empresa perteneciente a ese grupo haya participado en la política de largo plazo y

⁴ Estas consideraciones son similares a las mencionadas en la recomendación 212 relativa a la concesión de financiación tras la apertura de un procedimiento en el contexto de un grupo de empresas.

coherente del grupo; y que de buena fe el director haya asumido razonablemente que cualquier detrimento sufrido por su empresa se vea oportunamente compensado con otras ventajas. Otro enfoque admite que el director de una empresa del grupo actúe en interés de la sociedad matriz siempre que no perjudique la posibilidad de su empresa de pagar a sus propios acreedores, y el director esté autorizado, ya sea por los estatutos de la sociedad o por los accionistas, según que la empresa sea de propiedad total o parcial. La empresa perteneciente al grupo no debe ser insolvente en el momento en que el director actúa y no debe resultar insolvente a causa de esa actuación.

57. Como se señaló en la tercera parte (párrs. 75 a 80), algunas operaciones comerciales realizadas dentro del grupo pueden resultar operaciones entre personas allegadas y, por lo tanto, impugnables en el contexto de la insolvencia. En algunas legislaciones esas operaciones pueden también exponer al director a responsabilidad personal cuando la empresa del grupo ya era insolvente o si pasó a serlo a raíz de la operación. Otras operaciones o acciones no quedarían comprendidas en las disposiciones relativas a las partes allegadas, tales como las decisiones sobre actuar o no actuar (por ejemplo, no competir con otra empresa del grupo por una determinada oportunidad) o cambiar la función de la empresa (por ejemplo, vendiendo externamente los activos de la empresa miembro del grupo, ya sea para arruinarla o para convertirla en una “caja” para el grupo). Las disposiciones sobre partes allegadas no exigen que se tengan en cuenta los intereses de los acreedores.

b) Definición de “director” en el contexto del grupo de empresas

58. En el párrafo 20 *supra* se examina la segunda cuestión relativa a las circunstancias en que una empresa del grupo o su director (por ejemplo de una sociedad de carteras) puede ser considerado un director, incluso un director virtual (nota de pie de página 6), de otra sociedad del grupo. Algunas legislaciones no permiten que una empresa perteneciente a un grupo de empresas sea nombrada director de otra empresa del grupo, pero sí puede ser considerada como un director virtual de otra empresa. Esto puede ocurrir de distintas maneras, como por ejemplo cuando las juntas directivas de las dos sociedades están integradas por las mismas personas, cuando la mayoría de los miembros de la junta directiva de una sociedad del grupo es nombrada por la otra empresa, que tiene una posición dominante, cuando una sociedad controla la gestión y la adopción de decisiones financieras del grupo y cuando una empresa del grupo interfiere de manera sostenida y generalizada en la gestión de otra empresa del grupo, que suele darse en el caso de una sociedad matriz y de una filial controlada del mismo grupo.

59. En la tercera parte de la Guía Legislativa se examina la posibilidad de extender la responsabilidad por las deudas externas en el contexto del grupo y se señala (párr. 99) que en varios ejemplos donde la responsabilidad tal vez pueda hacerse extensiva a la sociedad matriz, esa responsabilidad podría incluir la responsabilidad personal de los integrantes de la junta directiva de la sociedad matriz (que podrían ser directores nombrados oficialmente, *de facto* o virtuales). Una de las principales dificultades para extender la responsabilidad en esos casos es probar que la actividad en cuestión muestra que la sociedad matriz ha actuado como director *de facto* o virtual de la otra sociedad del grupo.

B. Cuestiones que se deben examinar

60. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si se necesitan otras recomendaciones para dar respuesta a las cuestiones planteadas *supra*. ¿Convendría, por ejemplo, permitir que el director de una sociedad en la cercanía de la insolvencia tomara en consideración los intereses del grupo en su totalidad además de tener en cuenta los de su propia sociedad o debería centrarse exclusivamente en su propia sociedad? En segundo lugar, el Grupo de Trabajo ha acordado que un “director” a los fines del presente trabajo debería definirse de conformidad con la legislación nacional (véase el proyecto de recomendación ...). ¿Es esa definición suficientemente amplia para abarcar las consideraciones pertinentes a los grupos de empresas?

III. Cuestiones transfronterizas

61. En sus períodos de sesiones 39° y 40° el Grupo de Trabajo convino en que las cuestiones transfronterizas se examinaran en un futuro período de sesiones (véase el párr. 109 del documento A/CN.9/715 y el párr. 52 del documento A/CN.9/738). El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar cuáles de esas cuestiones deberían examinarse en el contexto de la labor actual y la manera de hacerlo.

D. Nota de la Secretaría sobre la insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 42º período de sesiones

(A/CN.9/WG.V/WP.109)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
Antecedentes	1-2
I. Introducción	3-9
II. Iniciativas mundiales: la labor de las organizaciones internacionales.	10-38
A. Junta de Estabilidad Financiera	10-25
B. Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, Banco de Pagos Internacionales.	26-34
C. Fondo Monetario Internacional	35-38
III. Enfoques regionales: la Unión Europea	39-58
IV. La labor de la CNUDMI y su pertinencia para la resolución de bancos y entidades financieras	59-64
Anexo	

Antecedentes

1. En su 43º período de sesiones, celebrado en junio de 2010, la Comisión examinó una propuesta para estudiar la viabilidad de elaborar un instrumento internacional de resolución transfronteriza de casos de insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5 y A/CN.9/709, párr. 5). Se acordó que la Secretaría preparara un informe amplio sobre todas o algunas de las cuestiones pertinentes¹. Debido a que la labor emprendida a nivel internacional y

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17), párr. 259.* Esas cuestiones eran las siguientes: a) determinar las cuestiones relacionadas particularmente con la liquidación de las instituciones financieras grandes y complejas; b) establecer un estudio comparativo de determinados ordenamientos jurídicos con respecto a los mecanismos para organizar una cooperación transfronteriza durante la liquidación de instituciones financieras grandes y complejas; c) establecer y resumir la labor realizada, o en curso de realización, por otras instituciones, así como el contenido de cualquier labor de esta índole en la esfera considerada; d) identificar los ámbitos y las cuestiones jurídicas en que podrían o deberían aplicarse directamente o por analogía los principios establecidos en la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia (2004) y la Ley Modelo de 1997 de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza; e) determinar posibles enfoques alternativos para facilitar y garantizar la cooperación transfronteriza durante la liquidación de instituciones financieras grandes y complejas; y f) formular recomendaciones relativas a la posible labor futura de la CNUDMI o de otros órganos, así como de legisladores u órganos de reglamentación nacionales en las esferas definidas.

nacional sobre los regímenes de insolvencia de bancos e instituciones financieras se encuentra en curso² y al volumen de esa labor, a la Secretaría le ha sido difícil hacer un seguimiento detallado de todos los acontecimientos. En consecuencia, el presente documento se centra en el párrafo c) de dicha propuesta y en él se describe la labor que han realizado (y siguen realizando) las organizaciones internacionales y regionales en la Unión Europea. En cierta medida, las cuestiones señaladas en el párrafo d) de la propuesta se han examinado en algunos de los trabajos de las organizaciones internacionales que se indican *infra*. Se podría preparar, si así lo solicitara el Grupo de Trabajo, una segunda nota de la Secretaría en la que constarían los detalles de algunos ordenamientos jurídicos nacionales, que se analizarían de acuerdo con las normas internacionales promulgadas por las organizaciones indicadas *infra*, especialmente en lo que respecta a las cuestiones transfronterizas, y dicha nota se podría examinar en su 43º período de sesiones en 2013 (véase la sección IV *infra*).

2. En el presente documento se examina la labor que han realizado (y siguen realizando) otras organizaciones internacionales, a saber, la Junta de Estabilidad Financiera, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. También se examina la relación entre esa labor y la labor llevada a cabo por la CNUDMI, tanto en el ámbito transfronterizo como en su relación con grupos de empresas.

I. Introducción

3. La insolvencia del Banco Barings en 1995 motivó la puesta en marcha de un proyecto realizado por el Grupo de los Treinta, en cooperación con INSOL International, para examinar los problemas que podrían surgir en la insolvencia transfronteriza de una institución financiera. En el informe final, publicado en 1998, se observó que no había un marco internacional para encuadrar los problemas jurídicos, financieros y de supervisión que se podrían plantear en cualquier tipo de insolvencia transfronteriza y, por lo tanto, una insolvencia transfronteriza de importancia en el sector financiero presentaría un riesgo sustancial para el sistema financiero internacional. El informe contiene 14 recomendaciones relativas a la preparación para desastres; la aprobación de licencias y el examen de supervisión; la necesidad de contar con diversos instrumentos de insolvencia y resolución con respaldo legislativo; la cooperación transfronteriza, incluidos el intercambio de información, el acceso y el reconocimiento de representantes de insolvencias extranjeras; los acuerdos modelo de compensación por saldos netos y la ejecutabilidad jurídica de los contratos financieros; y la cooperación entre supervisores y profesionales en insolvencia. En el informe se mencionó la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza, que se había aprobado en fecha reciente, y, si bien se reconoció que la aplicación de la Ley Modelo a las instituciones financieras probablemente sería limitada debido al régimen de supervisión especial para las entidades financieras en dificultades que existía en numerosos países, se sugirió, con todo, que muchos de los principios de la Ley Modelo serían aplicables a la insolvencia financiera.

² Por “resolución” se entiende la reestructuración de una institución con el fin de asegurar la continuidad de sus funciones esenciales, preservar la estabilidad financiera y restaurar la viabilidad de esa institución en su totalidad o en parte.

4. La crisis financiera mundial en rápida evolución, que comenzó en agosto de 2007, ilustró la persistencia de muchas de las deficiencias que en el estudio de 1998 se habían identificado en los regímenes e instrumentos existentes para hacer frente a la insolvencia de los bancos y otras instituciones financieras y, en particular, a sus repercusiones transfronterizas. Por cuanto muchos grupos financieros sistémicamente importantes realizan sus operaciones a nivel mundial, la aplicación descoordinada de los sistemas de resolución por las autoridades nacionales ha hecho mucho más difícil impartir continuidad a las funciones esenciales y asegurarse de que la carga financiera del proceso de resolución recaiga en los accionistas y acreedores y no en el sector público.

5. Las repercusiones de la crisis de 2007 hicieron que el Grupo de los Veinte³ y otras entidades formularan llamamientos a los órganos de reglamentación y las autoridades competentes para que fortalecieran, con carácter prioritario, la cooperación en la prevención, gestión y resolución de las crisis y reformaran los regímenes de resolución y las leyes sobre insolvencia a la luz de la experiencia reciente, con miras a cerciorarse de que propiciaran una resolución ordenada de las instituciones financieras transfronterizas grandes y complejas. Esos llamamientos tuvieron su origen en dos factores conexos. Primero, el establecimiento de un marco eficaz para la resolución de las instituciones financieras es esencial en toda estrategia encaminada tanto a asegurar la estabilidad financiera como a limitar el riesgo moral; segundo, un marco de resolución solo podrá ser eficaz si va acompañado de un riguroso mecanismo de coordinación transfronteriza⁴.

6. Esos llamamientos motivaron los trabajos, entre otros, del Consejo de Estabilidad Financiera, el Grupo de solución de problemas bancarios de carácter transfronterizo (CBRG) (un subcomité del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria), el Banco de Pagos Internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y, en el plano regional, la Unión Europea, así como la reforma legislativa en varias jurisdicciones. Las diferentes instituciones internacionales y regionales han preparado un número significativo de documentos y estudios, algunos de los cuales se mencionan en el presente documento y se enumeran en el anexo para facilitar la consulta.

7. En el presente examen se destacan diversas conclusiones de esos trabajos y las recomendaciones para mejorar la resolución transfronteriza de bancos e instituciones financieras.

Definición de “institución financiera”

8. En el documento del FMI se señala⁵ que la actividad principal de muchos grupos financieros internacionales es la actividad bancaria. Sin embargo, numerosos bancos transfronterizos forman parte de grupos financieros, cuyas actividades, que van mucho más allá de la simple aceptación de depósitos y concesión de préstamos, abarcan una gama completa de operaciones financieras extrabancarias. Se observa, por un lado, que algunos de los grupos financieros internacionales de mayor riesgo sistémico son, esencialmente, bancos de inversión e intermediarios con poca o

³ Declaración sobre el fortalecimiento del sistema financiero (Cumbre de Londres, abril de 2009); Declaración de los dirigentes de la Cumbre de Pittsburgh (octubre de 2009).

⁴ Informe del Fondo Monetario Internacional, junio de 2010, pág. 5.

⁵ *Ibid.*, pág. 6.

ninguna aceptación de depósitos y, por el otro, que algunos grupos financieros están liderados por grandes compañías de seguros de giro internacional. En consecuencia, dichos grupos se componen de entidades reguladas y no reguladas, y los elementos sustantivos de los mecanismos de resolución de instituciones financieras bancarias y no bancarias serán diferentes, aun cuando los mecanismos para coordinar las medidas de resolución puedan ser similares. En algunas jurisdicciones, las instituciones financieras no bancarias pueden estar sujetas a la ley de insolvencia de las sociedades, razón por la cual diferentes partes de un grupo financiero pueden estar sujetas a distintos regímenes de insolvencia.

9. La definición de qué constituye una institución financiera es, por lo tanto, una definición elástica, según la jurisdicción de que se trate, y muchos estiman que el término abarca bancos, compañías de seguros, fondos fiduciarios de inversión, entidades de crédito y financiación y corredores de cambios.

II. Iniciativas mundiales: la labor de las organizaciones internacionales

A. Junta de Estabilidad Financiera

10. En abril de 2009 el Foro sobre la Estabilidad Financiera (FEF)⁶ elaboró principios para la cooperación transfronteriza en la gestión de crisis, basados en parte en las recomendaciones contenidas en los trabajos de otras organizaciones⁷, así como en las enseñanzas extraídas de la crisis financiera, especialmente con respecto a los bancos y otras instituciones financieras. Los principios del FEF recomiendan que, en los preparativos para enfrentar las crisis financieras, las autoridades deben: formular instrumentos de apoyo para gestionar la crisis financiera transfronteriza; celebrar reuniones anuales para examinar los problemas y los obstáculos a una acción coordinada que pueden surgir al atender “situaciones de tensión grave en compañías específicas”; compartir información, en particular con respecto a las medidas para la gestión de crisis, en la medida en que así lo permitan los marcos jurídicos nacionales de las autoridades de resolución y los regímenes de confidencialidad; alentar a las compañías a establecer planes y procedimientos de emergencia para aplicarlos en situaciones de liquidación y planes de financiación; y colaborar para eliminar los obstáculos prácticos a las resoluciones coordinadas internacionalmente que podrían identificarse, por ejemplo, cuando se elaboran planes de emergencia. Respecto de la gestión de la crisis financiera, se recomendó que las autoridades: se esforzaran por encontrar soluciones coordinadas a escala internacional que tuvieran en cuenta las repercusiones de la crisis en los sistemas financieros y las economías reales de otros países; se comunicaran los resultados de las evaluaciones nacionales respecto de las implicaciones sistémicas; intercambiaran

⁶ El FEF fue sucedido por el Consejo de Estabilidad Financiera, creado por el Grupo de los Veinte en 2009, con la finalidad de, por un lado, coordinar a nivel internacional la labor de las autoridades financieras nacionales y los organismos normativos internacionales y, por el otro, elaborar y promover la aplicación de políticas eficaces en materia de reglamentación y supervisión y otras políticas del sector financiero.

⁷ El FEF, el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y el Informe Conjunto del Grupo de Trabajo del Grupo de los Diez (2001) sobre la liquidación de una institución financiera grande y compleja.

información tan libremente como fuera posible con las autoridades competentes desde un principio; examinaran las medidas nacionales, lo antes posible, con otras autoridades cuando se hubiera encontrado una solución coordinada; y compartieran información sobre los planes de acción para la comunicación pública con las autoridades de otras jurisdicciones afectadas.

11. Se observó que, si bien los efectos de la crisis se habían atendido a nivel nacional, era de suma importancia que se afianzara la cooperación internacional entre las autoridades de los países de origen con el fin de mitigar las perturbaciones sistemáticas causadas por las dificultades financieras de compañías interconectadas e integradas en gran medida. También se insistió en que las autoridades encargadas de la gestión de la crisis financiera deberían tener presentes, por un lado, la necesidad de promover soluciones del sector privado, y recurrir a las intervenciones del sector público solo cuando fuera necesario para preservar la estabilidad financiera, y, por el otro, la necesidad de mantener condiciones de igualdad en la competencia a nivel internacional en consonancia con los Acuerdos de Basilea.

12. En su llamamiento a la acción de 2009, el Grupo de los Veinte había pedido al Consejo de Estabilidad Financiera que explorara la viabilidad de formular normas y principios comunes para orientar prácticas o sistemas de resolución transfronteriza aceptables, lo que ayudaría a reducir los efectos negativos de la descoordinación de las medidas nacionales, incluido el coto financiero.

13. En 2010 el Consejo de Estabilidad Financiera elaboró una serie de recomendaciones para reducir el riesgo moral planteado por las entidades financieras de importancia sistémica, es decir, entidades cuyas dificultades o quiebra desordenada, debido a su escala, complejidad e interconexión sistémica, podrían causar perturbaciones significativas en el sistema financiero y la actividad económica en general⁸. Esas recomendaciones fueron las siguientes: todas las jurisdicciones deberían emprender reformas jurídicas para asegurar la institución de un régimen eficaz de resolución; cada país debería tener un organismo de resolución con facultades de resolución; las autoridades nacionales deberían estudiar mecanismos de recapitalización y métodos de reducción del valor del activo; las autoridades de resolución deberían estar obligadas a recabar la cooperación de las autoridades de resolución extranjeras; en el caso de determinadas instituciones, se deberían preparar acuerdos de cooperación entre las autoridades de los países de origen y de destino; debería ser obligatorio elaborar planes de recuperación y resolución que llevaran a evaluar la pertinencia de la resolución; la planificación debería ser un ejercicio permanente; las autoridades deberían estar facultadas para exigir que una entidad financiera modificara su estructura jurídica y operacional y sus prácticas institucionales a fin de facilitar la aplicación de las medidas de resolución y recuperación; la pertinencia de la resolución con arreglo a los regímenes y acuerdos de cooperación vigentes debería ser un factor importante cuando las autoridades del país de destino determinaran que se debían introducir cambios en las operaciones de una institución acogida en su jurisdicción; la información pertinente se debería almacenar en relación con cada institución por separado; y se debería reducir al mínimo el uso de las garantías intragrupo y, al propio tiempo, se debería asegurar que los mecanismos mundiales de pago y

⁸ Consejo de Estabilidad Financiera, Medidas sustantivas aplicables a las instituciones financieras sistemáticamente importantes, noviembre de 2011, párr. 3.

liquidación se pudieran separar jurídicamente sin que ello incidiera en la capacidad operativa.

14. En 2011, el Consejo de Estabilidad Financiera elaboró el documento titulado “Características esenciales para unos mecanismos eficaces de resolución de entidades financieras” (en lo sucesivo, “las características esenciales”), que el Grupo de los Veinte hizo suyo en noviembre de 2011. Las características esenciales tienen por objeto establecer normas internacionales relativas a la institución de regímenes de resolución eficaces y alentar la convergencia internacional; en muchas jurisdicciones se necesitarán reformas legislativas para ponerlas en práctica, y la aplicación deberá ser objeto de una evaluación permanente⁹. Las normas, que se refieren a las facultades, medidas y autoridades de resolución, tratan de abarcar toda institución financiera que pueda ser sistémicamente importante o crítica si cae en insolvencia, incluidas las compañías de cartera, las entidades operacionales no reguladas de un grupo financiero que sean importantes para la actividad del grupo y las sucursales locales de compañías extranjeras. Las entidades financieras constituidas en una jurisdicción que sean sistemáticamente importantes a nivel mundial, esto es, las entidades financieras de importancia sistémica cuyas dificultades o quiebra desordenada, debido a su escala, complejidad e interconexión sistémica, podrían causar perturbaciones significativas en el sistema financiero y la economía en general, deberían estar sujetas a algunos aspectos del régimen de resolución, incluidos la obligación de establecer planes de recuperación y resolución, las evaluaciones de la pertinencia de la resolución y los acuerdos de cooperación transfronteriza para entidades específicas.

1. Autoridad encargada de la resolución

15. El Consejo de Estabilidad Financiera propuso que en todas las jurisdicciones se estableciera una autoridad encargada de la resolución, con competencias jurídicas e institucionales para ejercer las facultades y aplicar medidas relativas a la resolución. Esas autoridades deberían tener funciones claramente definidas por ley, actuar con transparencia e independencia y estar en condiciones de concertar acuerdos relativos a entidades específicas con las autoridades de resolución de otras jurisdicciones. Asimismo deberían estar facultadas para actuar con miras a lograr una solución cooperativa con las autoridades de resolución extranjeras siempre que ello sea posible. La autoridad del país de destino debería estar facultada, no solo para apoyar una resolución impuesta por una autoridad del país de origen, sino también para adoptar medidas por propia iniciativa cuando la autoridad del país de origen no adopte medidas o las adopte sin tener suficientemente en cuenta la necesidad de preservar la estabilidad financiera de la jurisdicción de destino. El marco legal debería autorizar la ejecución de las medidas de resolución extranjeras, ya sea mediante el mutuo reconocimiento o la adopción de medidas que apoyen las medidas de la autoridad de resolución extranjera y sean compatibles con ellas.

⁹ *Ibid.*, párr. 11. En octubre de 2011, el Consejo de Estabilidad Financiera estableció un marco para vigilar la aplicación de esas reformas, el Marco coordinado de vigilancia de la aplicación, e intensificar la presentación de informes públicos sobre la aplicación. Véase Overview of Progress in the Implementation of the G20 Recommendations for Strengthening Financial Stability, Report of the Financial Stability Board to G20 Leaders, 19 de junio de 2012.

2. Facultades de resolución

16. El Consejo de Estabilidad Financiera hizo hincapié en la importancia de que a las autoridades de resolución se les atribuyeran facultades de resolución amplias que les permitieran intervenir la entidad financiera en dificultades. Entre los ejemplos de esas facultades cabe mencionar la transferencia de activos, la separación y reemplazo de la administración, la suspensión de pagos, la liquidación de la entidad y la suspensión temporal de los derechos de compensación recíproca, compensación contractual y rescisión anticipada. Las autoridades de resolución deberían estar preparadas para ejercer sus facultades lo antes posible cuando una entidad haya dejado o pueda dejar de ser viable y no tenga ninguna posibilidad razonable de recuperar su viabilidad. Deberían intervenir antes de que la entidad sea insolvente en su balance y de que su capital social se haya reducido a cero. Se deberían instituir normas claras o indicadores apropiados en materia de inviabilidad, a fin de impartir orientación respecto de cuándo las entidades reúnen las condiciones para el inicio del proceso de resolución.

3. Compensación recíproca, compensación por saldos netos y segregación de activos de los clientes

17. En el documento sobre las características esenciales se recomienda que el marco jurídico para la compensación recíproca, la compensación por saldos netos, la constitución de garantías y la segregación de los activos de los clientes sea claro, transparente y ejecutable. Las autoridades de resolución deben estar facultadas para suspender temporalmente el ejercicio de la rescisión anticipada o la declaración de caducidad de plazos como consecuencia exclusivamente del inicio del proceso de resolución¹⁰. La suspensión temporal debería aplicarse a los acreedores y clientes sin garantía, para prevenir, entre otras cosas, que se ejecuten medidas para embargar bienes o hacerse pago con el efectivo o los bienes de la entidad financiera, con sujeción a ciertas salvaguardias, tales como la protección de la ejecutabilidad de los derechos admisibles de compensación recíproca y de compensación por saldos netos.

4. Salvaguardias

18. El Consejo de Estabilidad Financiera propuso que las facultades de resolución se ejercieran de una manera que respetara la jerarquía de los créditos y diera un margen de flexibilidad para apartarse del principio general de *pari passu* cuando fuera necesario para contener las repercusiones sistémicas y elevar al máximo el valor para los acreedores en su conjunto. Sin embargo, no debería haber discriminación en perjuicio de los acreedores por razones de nacionalidad, domicilio de las reclamaciones o jurisdicción en la que se deban pagar los créditos, y ningún acreedor debería encontrarse en situación más desfavorable de la que le hubiera correspondido en caso de liquidación conforme al régimen de insolvencia aplicable. Se debería eximir a los directores de responsabilidad por las medidas que adopten en cumplimiento de decisiones de la autoridad de resolución.

¹⁰ La cuestión de la suspensión temporal se examina en el anexo IV del documento sobre las características esenciales.

5. Financiación de las entidades financieras en la resolución

19. Se recomendó que cada jurisdicción estableciera un fondo de resolución a fin de que las autoridades no estuvieran obligadas a recurrir a la propiedad pública o a fondos de rescate. Cuando se necesiten fondos públicos, se deberían establecer condiciones estrictas para reducir al mínimo el riesgo moral y asignar las pérdidas a los accionistas, los acreedores sin garantía y sin seguro y el sector.

6. Condiciones del marco jurídico para la cooperación transfronteriza

20. El documento hace hincapié en la necesidad de que el legislador establezca un mandato para atribuir facultades y alentar a las autoridades de resolución a actuar con miras a lograr una solución cooperativa con las autoridades de resolución extranjeras. La legislación nacional no debería contener disposiciones que impongan la adopción de medidas nacionales frente a una intervención extranjera o el inicio de la resolución en otra jurisdicción, a menos que se haya instituido un régimen eficaz de cooperación e intercambio de información. En el ejercicio de sus facultades, como se señaló *supra*, las autoridades de resolución deberían tener en cuenta las repercusiones en las entidades financieras de otras jurisdicciones. Deberían poseer facultades sobre las sucursales locales de entidades extranjeras y poder apoyar las resoluciones dictadas por las autoridades del país de origen o, en casos excepcionales, estar facultadas para tomar la iniciativa cuando la autoridad del país de origen se abstenga de adoptar medidas o cuando las medidas adoptadas no tengan suficientemente en cuenta la estabilidad financiera local. Se deberían establecer procedimientos para la ejecución de las medidas de resolución extranjeras, por ejemplo, mediante mutuo reconocimiento, y se deberían instituir mecanismos para proteger la confidencialidad de la información intercambiada.

7. Grupos de gestión de crisis

21. En el plano internacional, se recomienda que todas las entidades financieras mundiales de importancia sistémica establezcan grupos de gestión de crisis (GGC) a fin de mejorar su preparación para enfrentar una crisis financiera transfronteriza que afecte a la entidad y facilitar su gestión y resolución¹¹. Los GGC deberían incluir representantes de las autoridades de supervisión, los bancos centrales, las autoridades de resolución, los ministerios de finanzas y las autoridades públicas encargadas de los sistemas de garantía y deberían cooperar estrechamente con las autoridades de otras jurisdicciones en que las entidades financieras tengan una presencia sistémica.

8. Acuerdos de cooperación transfronteriza para entidades específicas

22. Se estima que el uso de acuerdos de cooperación para entidades específicas entre las autoridades de resolución para todas las entidades financieras mundiales de importancia sistémica es un elemento clave para el seguimiento de esas entidades. Los acuerdos, entre otras cosas, deberían establecer los objetivos y procedimientos

¹¹ En noviembre de 2011, el Consejo de Estabilidad Financiera publicó una lista inicial de entidades financieras mundiales de importancia sistémica (véase el anexo de las Medidas de política). Las entidades financieras mundiales de importancia sistémica deben cumplir con los requisitos de planificación de la resolución para el fin de 2012. La lista se actualizará anualmente y el Consejo de Estabilidad Financiera la publicará en noviembre de cada año.

de cooperación por medio de los GGC, definir las funciones y responsabilidades de las autoridades en la fase de recuperación y resolución y durante una crisis, instituir procedimientos para el intercambio de información, la formulación de planes de recuperación y resolución, la realización de evaluaciones de la pertinencia de la resolución y prever un calendario de reuniones y exámenes periódicos¹².

9. Evaluaciones de la pertinencia de la resolución y planificación de la recuperación y resolución

23. Las evaluaciones de la pertinencia de la resolución¹³ se consideran importantes para la formulación de estrategias de gestión de crisis de sistemas financieros. Las evaluaciones de la pertinencia de la resolución de un grupo de entidades deberían ser realizadas por las autoridades del país de origen y coordinadas con las autoridades del país de destino. Estas evaluaciones se deberían complementar con planes de recuperación y resolución (PRR), cuyos elementos esenciales figuran en el documento sobre las características esenciales¹⁴. Los PRR se han de actualizar como mínimo una vez al año o cuando se produzcan cambios sustanciales en el giro o la estructura de una entidad financiera y deberían ser examinados periódicamente por el GGC de la entidad. También, sobre todo en el caso de las entidades financieras mundiales de importancia sistémica, deberían tener en cuenta la naturaleza, complejidad, interconexión, nivel de sustituibilidad y escala de la entidad.

10. Acceso a la información e intercambio de información

24. La última característica esencial es el acceso a la información y su intercambio. Se recomienda que se eliminen todos los obstáculos jurídicos que impiden tanto el acceso a la información como el intercambio de información entre las autoridades nacionales de resolución, los bancos centrales nacionales y las autoridades de supervisión. A este fin, se propone que se instituyan sistemas para facilitar a) el intercambio de la información pertinente para planificar la recuperación y la resolución; b) el intercambio de información relacionada con las entidades financieras mundiales de importancia sistémica; y c) el manejo de la información sensible.

25. En las respuestas a la consulta pública sobre las características esenciales, el Consejo de Estabilidad Financiera expresó el parecer de que, si bien representaban un avance significativo, el marco jurídico para la cooperación transfronteriza, los GGC y los acuerdos de cooperación transfronteriza para entidades específicas no llegaban a constituir un marco vinculante para el mutuo reconocimiento y la cooperación internacional. Se reconoció que la formulación de mecanismos más vinculantes no sería viable si antes no se establecían, por un lado, los regímenes convergentes y, por el otro, los incentivos para la cooperación que deberían dimanar de la institución de las características esenciales.

¹² Los elementos esenciales de esos acuerdos figuran en el anexo I del documento sobre las características esenciales.

¹³ Estas evaluaciones se examinan con cierto detalle en el anexo II del documento sobre las características esenciales.

¹⁴ Véase el Anexo III.

B. Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, Banco de Pagos Internacionales

26. En agosto de 2003 el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (CBSB) del Banco de Pagos Internacionales adoptó los Principios de alto nivel para la aplicación transfronteriza del Nuevo Acuerdo. El Nuevo Acuerdo¹⁵ era una serie de directrices encaminadas a establecer un marco para determinar la adecuación del capital y un criterio mínimo que deberían lograr las autoridades de supervisión nacionales. Habida cuenta de que la coordinación y la cooperación constituían dos de las características principales del Nuevo Acuerdo, los seis principios de alto nivel se formularon para plasmar ese aspecto. Los principios de alto nivel hicieron hincapié en los siguientes aspectos: la importancia de reconocer y aplicar los requisitos reglamentarios nacionales para los bancos; el papel de los supervisores del país de origen en la supervisión de los grupos bancarios en base consolidada; la necesidad de que los bancos que operen mediante filiales comprendan y reconozcan los requisitos establecidos por los supervisores del país de destino; y la necesidad de coordinar las tareas de aprobación y validación y de intercambiar información como uno de los aspectos de la cooperación entre los supervisores de los países de origen y destino.

27. Entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009, el Grupo de solución de problemas bancarios de carácter transfronterizo (CBRG) del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria realizó una auditoría de los marcos jurídicos y normativos relativos a la resolución de crisis transfronterizas. Ese proceso tuvo por objeto determinar las enseñanzas extraídas de la crisis financiera que comenzó en agosto de 2007. Reconociendo que la mayor parte de las medidas de intervención frente a la crisis financiera se habían adoptado con carácter *ad hoc*, en marzo de 2010 el Comité elaboró un informe y un conjunto de diez recomendaciones -“Informe y recomendaciones del Grupo de solución de problemas bancarios de carácter transfronterizo”- para que las autoridades y legisladores nacionales los tuvieran en cuenta al elaborar leyes y políticas sobre la gestión transfronteriza de las resoluciones bancarias.

28. En el informe se llegó a las siguientes conclusiones: Muchos regímenes de gestión de crisis están centrados en el ámbito nacional y no se cuenta con un marco multinacional, lo cual da lugar a tensiones entre la naturaleza transfronteriza de los grupos financieros y los marcos y responsabilidades nacionales en materia de gestión de crisis, así como entre las evaluaciones nacionales de cómo se debe encarar una situación transfronteriza; por otra parte, el crecimiento no administrado, en particular la expansión transfronteriza de entidades financieras complejas, ha creado problemas cuando las autoridades de los países de origen no realizan una supervisión eficaz y no disponen de recursos para responder a esas crisis; la evolución acelerada de la crisis y las correlativas restricciones de tiempo limitan el uso de los instrumentos formales de los supervisores para la gestión de crisis y dificultan grandemente o impiden la cooperación entre jurisdicciones; hay una tensión entre la necesidad de una rápida resolución por razones de interés público y la posición de los accionistas (en algunas jurisdicciones no se pueden adoptar medidas especiales sin la aprobación de los accionistas); la centralización de la

¹⁵ Se puede consultar en www.bis.org/publ/bcbsca.htm.

gestión de la liquidez puede causar tensión dentro de un grupo transfronterizo; las estructuras de grupo crean interdependencias dentro de los grupos, que los reguladores y otras autoridades tienen que entender y controlar; las entidades financieras transfronterizas pueden estar sujetas a una supervisión consolidada por la autoridad del país de origen y a la supervisión y resolución de las filiales individuales por la autoridad del país de destino; es de presumir que la quiebra de las entidades transfronterizas culmine en procedimientos de insolvencia de sus entidades componentes sujetas a diferentes regímenes en distintas jurisdicciones con arreglo a diferentes políticas, prioridades y objetivos; la primacía de los intereses nacionales favorece la concentración en la parte nacional de un grupo en beneficio de las partes interesadas locales y la posible segregación de los activos (coto financiero); si bien ese enfoque tal vez propicie un mayor control sobre la gestión del capital, la liquidez y el riesgo para garantizar la protección de los acreedores del país de destino, al propio tiempo puede crear ineficiencias en la asignación de capital y liquidez dentro de un grupo.

29. En las recomendaciones formuladas por el CBRG se hace hincapié en la necesidad de que se establezcan marcos nacionales apropiados de resolución con el fin de mantener la estabilidad financiera, proteger a los consumidores, limitar el riesgo moral, promover la eficiencia del mercado y reducir al mínimo el riesgo sistémico. Esos marcos tienen que coordinar los diferentes procedimientos de gestión de crisis y resolución que se aplican a las distintas actividades de los grupos financieros, promover la continuidad de las funciones de importancia sistémica e incluir instrumentos apropiados, tales como las facultades para crear entidades financieras puente, transferir activos, pasivos y operaciones comerciales a otras entidades y resolver las reclamaciones. Se recomienda la convergencia de los instrumentos de resolución y medidas nacionales.

30. Los marcos de resolución deberían tener en cuenta a los grupos y conglomerados financieros que operan en las jurisdicciones nacionales y promover la cooperación entre las autoridades nacionales mediante el establecimiento de procedimientos para el mutuo reconocimiento de los procedimientos de gestión de crisis y de las actuaciones y medidas relacionadas con la resolución, en particular cuando intervienen grandes grupos financieros vinculados entre sí. El reconocimiento se podría instrumentar a nivel bilateral o en los planos regional o internacional.

31. Dado que la complejidad de las entidades financieras puede dificultar una resolución ordenada y eficaz en función de los costos, el CBRG recomienda que los supervisores colaboren estrechamente con las autoridades de resolución competentes de los países de origen y de destino con el fin de que entiendan en qué forma las estructuras de grupo y sus distintos componentes se pueden resolver en una crisis y, cuando esas estructuras sean demasiado complejas como para permitir la resolución, de que elaboren incentivos regulatorios que fomenten la simplificación de las estructuras de grupo.

32. En las recomendaciones también se mencionan la planificación anticipada para una resolución ordenada como un componente ordinario de la supervisión que tiene en cuenta las dependencias transfronterizas y las implicaciones de la separación jurídica; la cooperación transfronteriza y el intercambio transfronterizo de información, tanto en tiempos normales como para la gestión de crisis en situaciones de tensión financiera; y el fortalecimiento de los mecanismos de mitigación de riesgo, como los acuerdos ejecutables de compensación por saldos netos, la constitución de

garantías y la segregación de las posiciones de los clientes. Con el fin de completar la transferencia de determinados contratos del mercado financiero a entidades financieras solventes, se recomienda que se posponga por un breve plazo la aplicación de las cláusulas contractuales de rescisión y que se preserven los derechos contractuales de rescindir y compensar y de ejecutar garantías. Por último, las recomendaciones subrayan la necesidad de ofrecer opciones claras para que la entidad financiera pueda salir de la intervención pública.

33. Si bien en el informe se dice que se debería estudiar si la labor de la CNUDMI sobre grupos de empresas podría informar los trabajos encaminados a mejorar la coordinación de los procedimientos de resolución de grupos financieros, al propio tiempo se reconoce que no trata las múltiples cuestiones singulares que abarca la resolución de grupos financieros. Sin embargo, se aconseja a las autoridades y encargados de la formulación de políticas en el plano nacional que analicen si las recomendaciones de la CNUDMI en la tercera parte de la Guía Legislativa sobre la mejora de la eficiencia de los procedimientos de insolvencia de los grupos de sociedades son aplicables a los procedimientos de insolvencia de los grupos financieros. También se recomienda a las entidades nacionales que prevean el reconocimiento de las medidas de insolvencia extranjeras y el acceso de los representantes extranjeros a los tribunales y bienes del deudor en la jurisdicción de la entidad nacional¹⁶.

34. En el informe también se señala que una posibilidad podría ser la de tomar las medidas necesarias para establecer un amplio marco universal para la resolución de los grupos financieros transfronterizos, en el que se podría asignar primacía a la jurisdicción donde la entidad tenga su sede. En el informe se añade que dicho marco tendría que abarcar una serie de cuestiones complejas, incluidas algunas de las que se ha ocupado la Guía Legislativa, a saber, facultades de anulación, régimen de los créditos intragrupo, orden de prelación de los créditos, derechos de compensación recíproca y compensación por saldos netos, régimen de ciertos contratos financieros, presentación y admisión de créditos y distribución a los acreedores.

C. Fondo Monetario Internacional

35. En abril de 2009, el FMI y el Banco Mundial prepararon un estudio titulado “An Overview of the Legal, Institutional and Regulatory Frameworks for Bank Insolvency”, en el que se examinan las características principales de los marcos jurídicos, institucionales y regulatorios necesarios para hacer frente eficazmente a la insolvencia de bancos (es decir, solamente de las entidades que reciben depósitos) a nivel nacional (no se analizan los problemas de insolvencia transfronteriza de bancos) en períodos de estabilidad financiera y de crisis sistémica. En el documento se examinan los tipos de procedimientos de insolvencia de bancos a los que se puede recurrir en tiempos de estabilidad financiera, las facultades y responsabilidades de todos los organismos que intervienen en dichos procedimientos y las fases pertinentes, así como consideraciones de carácter general, arreglos institucionales y

¹⁶ Esta recomendación está en consonancia con las recomendaciones de la CNUDMI sobre el reconocimiento de procedimientos extranjeros y representantes extranjeros, y la cooperación con representantes extranjeros (Guía Legislativa, tercera parte, capítulo III, recomendaciones 239 a 254).

regímenes reglamentarios y jurídicos aplicables a la gestión de crisis sistémicas. La razón fundamental de este documento es que las recientes turbulencias en los mercados financieros han destacado la importancia de que los países instituyan marcos jurídicos, institucionales y reglamentarios para la resolución de bancos insolventes. En el documento se señala que “si bien no existe un consenso firme sobre una única norma o modelo que los países deberían emplear en la formulación de un régimen de insolvencia bancaria, se reconocen cada vez más muchas de las prácticas que deberían observarse para tal fin”¹⁷.

36. En junio de 2011 el FMI publicó un documento titulado “Resolution of Cross-Border Banks - a proposed framework for enhanced coordination”, en que se examinó la necesidad de un marco para mejorar la coordinación con miras a mitigar los efectos de la aplicación descoordinada de los regímenes de resolución de grupos financieros internacionales (que podrían abarcar una entidad bancaria o basarse en ella, pero cuyas actividades muchas veces van más allá de la captación de depósitos e incluyen una amplia gama de actividades financieras extrabancarias, muchas de ellas a nivel transfronterizo) por parte de las autoridades nacionales. El documento responde al llamamiento de los dirigentes del Grupo de los Veinte mencionado *supra* (párr. 5) y se basa en los trabajos del CBRG. También hace referencia al marco de coordinación y cooperación recomendado en la tercera parte de la Guía Legislativa de la CNUDMI y a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza.

37. En el contexto de los efectos de la falta de coordinación observada en la intervención de diversas entidades financieras transfronterizas en dificultades¹⁸, como consecuencia de la crisis financiera global y los impedimentos opuestos a la elaboración de un marco coordinado, el documento enuncia cuatro elementos importantes encaminados a lograr una mayor coordinación, a saber:

a) La reforma de las leyes nacionales para disponer que las autoridades nacionales deben coordinar los procedimientos de resolución con sus colegas de otras jurisdicciones en la máxima medida posible, en consonancia con los intereses de los acreedores y la estabilidad financiera nacional. Se observa que los países cuya legislación prohíbe el intercambio de información con las autoridades de resolución extranjeras y propicia el coto financiero tal vez no estén en condiciones de mejorar la coordinación sin antes reformar sus leyes nacionales;

b) La adopción de normas de coordinación básicas relacionadas con la estructuración y aplicación de sistemas de resolución para facilitar el uso de un marco de mayor coordinación, que hayan sido acordadas y aplicadas por los países coordinadores. Esta propuesta se basa en el argumento de que las autoridades nacionales solo estarían dispuestas a coordinar sus actividades si tienen confianza suficiente en sus contrapartes. Estas normas de coordinación abarcarían lo siguiente: i) un nivel mínimo de armonización de las normas nacionales de resolución, incluida la no discriminación de los acreedores extranjeros, instrumentos de intervención eficaces y salvaguardias apropiadas; ii) una supervisión rigurosa que permita a los supervisores del país de destino aceptar la dirección de los supervisores del país de origen y sentir la confianza de que podrán aplicar una

¹⁷ Estudio del FMI y el Banco Mundial, 2009, pág. 13.

¹⁸ Entre ellos el aumento del riesgo moral, la destrucción de valor en las entidades financieras, la inestabilidad financiera, etc.; véase FMI, “Enhanced Coordination”, pág. 12.

solución internacional y colaborar con otros supervisores de los países de origen; y
iii) una capacidad institucional que permita una acción transfronteriza rápida para aplicar una solución internacional;

c) La reducción al mínimo del uso de recursos fiscales y la enunciación de principios que orienten el proceso de distribución de la carga entre las autoridades cooperantes cuando se necesiten esos recursos. Uno de los objetivos fundamentales de este marco es que los costos finales de resolución sean asumidos por los interesados privados y que se eviten los rescates con recursos del Estado. Sin embargo, cabe señalar que la disponibilidad de financiación de interesados privados puede ser limitada y, por lo tanto, en algunos casos quizás haya que recurrir a una combinación de recursos de los sectores público y privado. Por otra parte, se señala que los países de origen bien pueden no estar dispuestos a proporcionar apoyo a un grupo financiero internacional que esté pasando por una crisis y, en algunos casos, tal vez no estén en condiciones de hacerlo. En consecuencia, los países de destino deberían estar dispuestos a suministrar fondos para estabilizar a esas entidades financieras;

d) El establecimiento, entre los países que se adhieran al marco de mayor coordinación, de procedimientos de coordinación que sirvan de mecanismo para la adopción de medidas de resolución con repercusiones transfronterizas en una crisis. Se precisa claridad respecto de quién ha de desempeñar la función rectora de iniciar y llevar adelante los procedimientos de resolución; se propone que esa función se encomiende a las autoridades del país de origen y que el país de destino acepte la función rectora de un país de origen que tenga instituidas normas de coordinación similares. Sin embargo, el país de destino también se reservaría el derecho de actuar de manera independiente, si fuera necesario para asegurar la estabilidad financiera nacional. En consonancia con la tercera parte de la Guía Legislativa de la CNUDMI¹⁹, se recomienda que, tan pronto como sea posible, se establezcan vías de comunicación e intercambio de información, que son esenciales para que la coordinación sea satisfactoria. A ese fin, se sugiere que los acuerdos de cooperación para entidades y casos específicos, similares a los propuestos en la obra de la CNUDMI²⁰, serían muy útiles para simplificar las modalidades de comunicación.

38. El enfoque de un marco multilateral para una mayor coordinación encuentra sustento en el informe del CBRG de 2010, en el que se propuso un enfoque intermedio de la gestión de crisis para la resolución transfronteriza de las entidades financieras, a diferencia de los enfoques territorial (desglobalización de las entidades financieras) o universal (un tratado internacional vinculante). En el documento se señala que, a pesar de que las características específicas de la insolvencia de las sociedades mercantiles no son aplicables al sector de los servicios financieros, ese enfoque multilateral podría sustentarse en la labor de la CNUDMI en materia de insolvencia de las sociedades mercantiles (la Ley Modelo y la Guía Legislativa), pues se refiere al reconocimiento de los procedimientos de insolvencia en jurisdicciones extranjeras, la cooperación entre tribunales, los representantes de

¹⁹ Guía Legislativa de la CNUDMI, tercera parte, capítulo I, párr. 17.

²⁰ Ley Modelo de la Insolvencia Transfronteriza, artículo 27; Guía Legislativa de la CNUDMI, capítulo III, párrs. 48 a 54, recomendaciones 253 y 254; Guía de Prácticas de la CNUDMI sobre Cooperación en la Insolvencia Financiera.

la insolvencia y el uso de acuerdos transfronterizos en los casos de múltiples procedimientos de insolvencia transfronteriza en un grupo de empresas.

III. Enfoques regionales: la Unión Europea

39. En el curso de la crisis financiera se puso de manifiesto que ni los bancos ni las autoridades en la Unión Europea estaban preparados para tratar de resolver los problemas que surgieron. La planificación de contingencia era insuficiente; no todos los Estados Miembros tenían facultades para intervenir, estabilizar y reorganizar los bancos en dificultades en una fase temprana; los instrumentos y competencias para gestionar las quiebras de los bancos eran insuficientes; y los importantes perjuicios sistémicos causados por la quiebra de bancos grandes e independientes obligaron a las autoridades a utilizar recursos de los contribuyentes para el rescate. En particular, a pesar de que el funcionamiento transfronterizo de los bancos se ha ido integrando, al punto de que los ramos de actividad y los servicios internos están profundamente conectados entre sí, traspasando las fronteras geográficas de los Estados miembros, la facultad de intervención de las autoridades ha seguido teniendo un carácter nacional y, por consiguiente, se han empleado métodos de resolución bancaria ineficientes y potencialmente opuestos²¹.

40. En 2009, la Comisión anunció planes para establecer un marco comunitario para la gestión de crisis en el sector financiero, junto con un calendario de acción (COM (2009) 561 final). La primera etapa fue la aprobación de una propuesta legislativa sobre la recuperación y resolución de los bancos (mediados de 2011). La segunda etapa fue examinar la necesidad de una mayor armonización de los regímenes de insolvencia de los bancos, con el objetivo de resolverlos y liquidarlos con arreglo a las mismas normas sustantivas y procesales (para el fin de 2012). La tercera etapa incluiría el establecimiento de un régimen de resolución integrado, posiblemente basado en una única autoridad europea de resolución, que dependería de la adopción de un conjunto único de normas sustantivas con respecto a la resolución e insolvencia (para 2014). El proceso ha incluido varias rondas de consulta pública, una colaboración estrecha con el Consejo de Estabilidad Financiera y el Grupo de los Veinte y el seguimiento de otros acontecimientos internacionales.

41. En junio de 2010 el Parlamento Europeo adoptó por propia iniciativa un informe sobre las recomendaciones en materia de gestión de crisis transfronteriza en el sector bancario (A7-0213/2010), en el que puso de relieve la necesidad de contar con un marco conjunto a escala de la Unión para gestionar los bancos en situación de crisis financiera. En diciembre de 2010 el Consejo (ECOFIN) adoptó unas conclusiones que abogaban por la instauración de un marco de prevención, gestión y resolución de crisis (17006/1/10), que debería aplicarse a bancos de todos los tamaños, mejorar la cooperación transfronteriza y estar compuesto por tres pilares: medidas preparatorias y preventivas, intervención temprana e instrumentos y competencias de resolución. Al fin de mayo de 2012 la Comisión indicó que iniciaría un proceso para trazar los pasos principales hacia una plena Unión Económica y Monetaria que incluiría, entre otras cosas, el avance hacia una unión

²¹ SWD (2012) 167 final, pág. 2.

bancaria con supervisión financiera integrada y un único sistema de garantía de depósitos (COM (2012) 299).

42. El 6 de junio de 2012 la Comisión presentó una propuesta legislativa sobre recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de inversión (COM (2012) 280/3), que incluye un proyecto de directiva. En la propuesta se establecen los pasos y las competencias, los recursos, la capacidad operacional y los conocimientos especializados necesarios para que las autoridades pertinentes puedan hacer frente preventivamente a las crisis bancarias y asegurar que las quiebras de bancos en la Unión Europea se gestionen de manera que se evite la inestabilidad financiera y se reduzcan al mínimo los costos para los contribuyentes.

43. La propuesta consta de los tres elementos señalados en el informe del ECOFIN: a) medidas preparatorias y planes para reducir al mínimo los riesgos de problemas potenciales, verificando la capacidad de las entidades financieras para hacer frente a “acontecimientos económicos adversos” (preparación y prevención); b) en caso de aparición de problemas, unas competencias que permitan detener el deterioro de la situación del banco en una fase temprana con el fin de evitar su insolvencia (intervención temprana); c) si la insolvencia de una entidad es motivo de preocupación por lo que respecta a la defensa del interés público general, un medio eficaz para reorganizar o liquidar el banco de forma ordenada, manteniendo al mismo tiempo sus funciones esenciales y limitando al máximo la exposición de los contribuyentes a pérdidas por insolvencia (resolución). La resolución constituye una alternativa a los procedimientos de insolvencia ordinarios que atiende adecuadamente a la necesidad de evitar trastornos de la estabilidad financiera, mantiene servicios esenciales y protege a los depositantes. También se pretende eliminar la seguridad implícita de rescate público de las entidades financieras. En las etapas segunda y tercera se hace hincapié en la necesidad de ampliar la coordinación y la cooperación transfronterizas como componente clave del marco. Las competencias examinadas deberían estar a disposición de las autoridades pertinentes frente a cualquier banco, con independencia de su tamaño o ámbito de actividad.

44. En el marco se reconoce la importancia de los grupos transfronterizos como uno de los motores de la integración de los mercados financieros en la Unión Europea y establece normas particulares para esos grupos en cada una de las tres etapas, así como respecto de la transferencia de activos entre entidades vinculadas a un grupo en períodos de tensión financiera.

1. Ámbito

45. La propuesta abarca la gestión de las crisis en relación con todas las entidades de crédito y algunas empresas de inversión en la Unión Europea. Se aplicará a las sociedades de cartera cuando una o varias filiales de una entidad de crédito o empresa de inversión cumplan las condiciones de resolución y cuando sea necesaria la aplicación de los instrumentos y competencias de resolución respecto a una o varias filiales de una entidad matriz o respecto al grupo en su conjunto²².

²² Exposición de motivos, COM (2012) 280/3, pág. 10.

2. Autoridades de resolución

46. La propuesta requiere que los Estados miembros confieran competencias de resolución a las autoridades apropiadas que dispongan de experiencia y recursos adecuados para gestionar la resolución de crisis bancarias a nivel nacional y transfronterizo.

3. Los tres elementos

a) Etapa preparatoria y preventiva

47. Cada entidad deberá elaborar planes de rescate que establezcan acuerdos y medidas que le permitan adoptar providencias tempranas para restaurar su viabilidad a largo plazo en caso de grave deterioro de su situación financiera; los grupos financieros deberán elaborar planes tanto para el grupo como para cada una de las entidades que los compongan. Sobre la base de esos planes, las autoridades de resolución evaluarán si una entidad puede ser objeto de resolución; si detectan obstáculos significativos, podrán requerir que la entidad o el grupo adopte medidas para abordar esos obstáculos, tales como reducir su complejidad mediante modificaciones de su estructura legal u operativa, limitar el riesgo estableciendo un nivel máximo a nivel individual y agregado y restringir o impedir el desarrollo de nuevos productos o ramos de actividad. La pertinencia de la resolución de grupos será evaluada conjuntamente por todas las autoridades de resolución competentes y, por lo tanto, requerirá una coordinación y cooperación eficaces.

48. En la directiva propuesta (considerando 22) se señala que la prestación de apoyo financiero de una entidad de un grupo transfronterizo a otra entidad del mismo grupo está actualmente restringida en virtud de muchas legislaciones nacionales. Aunque su objeto es proteger a los acreedores y accionistas de cada entidad, en esas leyes no se tienen en cuenta la interdependencia de las entidades del mismo grupo o el interés del grupo. En consecuencia, en la propuesta se prevé que las entidades de un grupo puedan brindar apoyo financiero a otras entidades en la forma de préstamos, garantías o suministro de activos utilizables como garantía a favor de un tercero, con arreglo a los acuerdos establecidos y aprobados (de conformidad con las leyes nacionales) antes de que se produzcan las dificultades financieras. Los acuerdos son voluntarios, lo que permitirá a los grupos estimar si redundan en beneficio del grupo e identificar a las empresas del grupo que deberían ser partes en él. El supervisor de la empresa del grupo que preste esa ayuda financiera estará facultado para prohibirla o restringirla cuando dicha ayuda pueda poner en peligro la liquidez o solvencia de la empresa.

b) Etapa de intervención temprana

49. En la propuesta se amplían las competencias de los supervisores para intervenir en una etapa temprana en los casos en que la situación financiera o la solvencia de una entidad se esté deteriorando, que puede incluir la posibilidad de exigir a la entidad que aplique los acuerdos y medidas establecidos en el plan de rescate, elaborar un programa de acción con su calendario de aplicación y nombrar un administrador especial para reemplazar a los directivos de la entidad.

c) Etapa de resolución*i) Condiciones de resolución*

50. En la propuesta se establecen parámetros comunes para la activación de los instrumentos de resolución. De acuerdo con esos parámetros, en caso de insolvencia o casi insolvencia de una entidad las autoridades podrían intervenir cuando, si no se adoptara ninguna medida, la entidad pasara a ser insolvente en el futuro inmediato, siempre que no se disponga de ninguna otra solución que permita restablecer la solvencia de la entidad en un plazo adecuado y que las medidas de resolución se puedan justificar por razones de interés público.

ii) Principios generales

51. En el ejercicio de las competencias de resolución se deberán respetar los principios que se mencionan seguidamente. Las pérdidas deben asignarse en primer lugar a los accionistas y las pérdidas residuales, a los acreedores sin garantía. Los acreedores de una misma categoría pueden ser tratados de forma desigual solo si está justificado por razones de interés público y con el fin de fortalecer la estabilidad financiera. En aquellos casos en que los acreedores reciban menos de lo que habrían recibido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios, la diferencia será abonada por el fondo de resolución.

iii) Instrumentos de resolución

52. Se sugieren diversos instrumentos de resolución, incluida la venta de actividades (venta de la totalidad o una parte de los activos de la entidad de crédito en condiciones de mercado sin requerir el consentimiento de los accionistas o tener que cumplir exigencias de procedimiento que se aplicarían en otras circunstancias); la constitución de una entidad puente (transferencia temporal de la totalidad o una parte de las actividades de la entidad a una entidad controlada por el sector público, con el objetivo último de vender la empresa); la segregación de activos (la transferencia de activos deteriorados o problemáticos de una entidad financiera a una estructura de gestión de activos con objeto de asegurar su uso y gestión eficaz); y la recapitalización (depreciación de las deudas de todos o algunos de los acreedores no garantizados de una entidad en dificultades y conversión de los créditos en capital).

53. Los instrumentos de resolución han de aplicarse por separado o conjuntamente y pueden complementarse con instrumentos y competencias nacionales específicos, siempre que sean compatibles con el marco de resolución de la Unión y el Tratado y no opongan obstáculos a la resolución efectiva del grupo (por ejemplo, la delimitación de partes dentro de una entidad (coto financiero) no sería compatible con el marco).

iv) Restricciones y mecanismo de salvaguarda

54. Para una aplicación eficaz de los instrumentos de resolución, se puede imponer una suspensión temporal de los derechos de los acreedores y las contrapartes a ejecutar sus créditos y a liquidar, acelerar o extinguir de otro modo los contratos con una entidad en graves dificultades. Se pretende así establecer un plazo muy breve (que no se prolongará más allá del cierre de operaciones del día siguiente al de su

imposición), durante el cual se puedan identificar y valorar los contratos que deban transferirse a un tercero solvente, sin el riesgo de que el valor y el ámbito de aplicación de los contratos financieros se modifiquen al ejercer las contrapartes sus derechos de rescisión. La transferencia a un tercero solvente no se considerará un caso de incumplimiento que justifique el ejercicio de los derechos de rescisión. Se prohíbe que las autoridades hagan una aplicación selectiva (escisión de contratos, derechos o pasivos vinculados): los acuerdos vinculados (incluidos acuerdos de compensación recíproca y compensación por saldos netos, acuerdos de garantía financiera mediante transferencia de títulos de dominio, acuerdos de garantía y acuerdos de financiación estructurada) se deben transferir en bloque o no transferirse en absoluto.

55. Si bien las partes afectadas tienen derecho a un proceso justo y las decisiones adoptadas por las autoridades de resolución deberían ser objeto de revisión judicial, dicha revisión no afectará los actos administrativos o las transacciones celebradas en virtud de una decisión que posteriormente podría ser anulada. Las medidas correctivas deben limitarse a una indemnización por el daño ocasionado.

v) *Resolución transfronteriza*

56. Se incluyen medidas que harán necesaria una mayor cooperación entre las autoridades nacionales, con el debido respeto de la división de responsabilidades entre las autoridades de los países de origen y destino, y el establecimiento de incentivos para aplicar un enfoque de grupo en todas las fases de preparación, rescate y resolución. Se establecerán colegios de autoridades de resolución con una clara función de liderazgo para elaborar planes de resolución de grupos, analizar los obstáculos que impidan la aplicación eficaz de los instrumentos y competencias de resolución, elaborar modalidades comunes para la aplicación de esos instrumentos, crear un marco para acordar planes de resolución de grupos y coordinar decisiones y medidas entre las autoridades de resolución.

57. Cuando intervengan terceros países, las autoridades de resolución de la Unión deberán tener las competencias necesarias para apoyar y reconocer las medidas de resolución extranjeras respecto de un banco extranjero en quiebra y para aplicar instrumentos de resolución a las sucursales nacionales de entidades de terceros países cuando sea necesaria una resolución aparte por razones de estabilidad financiera o de protección de los depositantes locales. Este apoyo solo se facilitará si las medidas extranjeras garantizaron un trato equitativo e igualitario de los depositantes y acreedores del Estado miembro y no pusieron en peligro la estabilidad financiera en ese Estado miembro. Los acuerdos de cooperación con las autoridades de resolución extranjeras son necesarios para que las autoridades de la Unión puedan apoyar a dichas autoridades extranjeras y asegurar una planificación, toma de decisiones y coordinación eficaces en relación con los grupos internacionales. La Autoridad Bancaria Europea deberá celebrar acuerdos administrativos marco con terceros países y las autoridades de resolución nacionales deben celebrar acuerdos bilaterales en consonancia con esos acuerdos marco.

58. Por último, se propone que cada Estado miembro cree un fondo de resolución bancaria para sufragar los costos incurridos por las autoridades de resolución en la aplicación de los instrumentos de resolución. El objetivo es mejorar diversos aspectos de la cooperación transfronteriza y reducir la carga sobre los contribuyentes. Se espera

que hagan contribuciones al fondo las entidades financieras y algunas empresas de inversión de cada Estado miembro.

IV. La labor de la CNUDMI y su pertinencia para la resolución de bancos y entidades financieras

59. El nivel de actividad que se ha centrado en los mecanismos de resolución bancaria desde la crisis financiera de 2007 se asemeja a la actividad relacionada con los regímenes de insolvencia nacionales tras las crisis financieras del decenio de 1990, que tuvo por objeto determinar tanto las deficiencias de esos regímenes como las mejores prácticas que deberían servir de base para la reforma legislativa. Esa actividad quedó plasmada, en última instancia, en la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia.

60. La labor resumida *supra* abarca muchas de las cuestiones que se examinaban entonces, no solo en el contexto de la obra de la CNUDMI sobre la insolvencia de los grupos de empresas, en particular en un contexto transfronterizo, sino también los elementos de la Guía Legislativa en lo que respecta a los regímenes nacionales de insolvencia mercantil, aunque en ambos casos en esa obra no se trataron las cuestiones que interesan exclusivamente a las entidades financieras. Si bien en la definición de “empresa” en la tercera parte de la Guía se observa que no se pretende abarcar entidades a las que no sea aplicable el régimen de insolvencia, también se observa que los bancos suelen formar parte de grupos de empresas multinacionales²³. Sin embargo, hay similitudes, como se señala en el informe del FMI. Del mismo modo, gran parte del análisis en el informe del CBRG sobre las dificultades relacionadas con el trato de los grupos financieros se hace eco de las cuestiones examinadas por el Grupo de Trabajo V en la preparación de la tercera parte de la Guía Legislativa, particularmente en lo relativo a los problemas conceptuales vinculados a la segregación de entidades y los diferentes enfoques jurídicos para el trato de los intereses del grupo, así como a la aplicación del concepto de centro principal de intereses a los grupos de empresas y la necesidad de una amplia cooperación transfronteriza en materia de insolvencia.

61. Entre las cuestiones comunes mencionadas en la labor indicada *supra* cabe mencionar las siguientes: la necesidad de coordinación y cooperación transfronterizas y alguna forma de reconocimiento de las actividades de resolución extranjeras que les aporte efecto jurídico; la utilidad de los acuerdos de cooperación transfronteriza, aplicables a entidades específicas o entre autoridades de supervisión; la necesidad de financiación y, en particular, de que en la legislación aplicable se autorice la financiación intragrupo; la necesidad de un trato integrado de los grupos y los problemas planteados por el principio de la entidad única; la necesidad de criterios normalizados eficaces para la apertura de la resolución bancaria y de instrumentos y competencias eficaces para facilitar la resolución; salvaguardias para que ningún acreedor se encuentre en una situación más desfavorable de la que le hubiera correspondido en caso de liquidación y para que no haya discriminación en perjuicio de los acreedores por razones de nacionalidad o domicilio; y la conveniencia de una mayor convergencia de los regímenes de insolvencia bancaria o por lo menos de

²³ Guía Legislativa, tercera parte, párr. 9.

algunos aspectos específicos de esos regímenes, como las competencias de anulación, el trato de cláusulas *ipso facto* y la aplicación de la suspensión.

62. Aunque en el informe del FMI se señala la necesidad de incluir un marco de resolución bancaria en un tratado o instrumento internacional jurídicamente vinculante que pueda asegurar la convergencia de los regímenes de resolución nacionales, para facilitar así la cooperación y la coordinación transfronterizas, también se hace mención de las dificultades de elaborar un instrumento de esa índole, como se hace en la obra de la CNUDMI relativa al trato de los grupos transfronterizos. La cuestión de la posibilidad de elaborar ese tipo de instrumento forma parte del mandato actual del Grupo de Trabajo V y aún no se ha tratado. En ausencia de dicho instrumento, sin embargo, los enfoques adoptados en la tercera parte de la Guía Legislativa y la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza indican el mejor camino por seguir, sirviendo de inspiración para formular mecanismos de resolución bancaria y tratar de resolver las cuestiones transfronterizas.

63. La labor resumida *supra* muestra la aparición de diversos principios comunes que se deben reflejar en los mecanismos de resolución que se están elaborando, como los contenidos en el informe y las recomendaciones del CBRG y en las características esenciales del Consejo de Estabilidad Financiera, cuya aplicación está siendo supervisada por el Consejo de Estabilidad Financiera. La legislación está en constante desarrollo. Se puede considerar que esas recomendaciones y características desempeñan en alguna medida una función con respecto a los regímenes de resolución de entidades bancarias y financieras similar a la función que desempeña la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia con respecto al régimen de la insolvencia mercantil, pues abarcan objetivos fundamentales, principios básicos y otros elementos que deberían formar parte de un régimen de insolvencia eficaz y eficiente, aunque de manera menos detallada.

64. La cuestión que se debe examinar a la luz de la labor descrita en el presente documento es en qué medida y de qué manera podrían ser objeto de la labor de la CNUDMI los aspectos de la propuesta mencionados en el párrafo 1 *supra*. Como se señaló en el párrafo 1, se podría preparar una segunda nota en que se examinaran los detalles de algunos ordenamientos jurídicos nacionales de resolución bancaria, especialmente en lo que respecta a las cuestiones transfronterizas, con miras al 43º período de sesiones del Grupo de Trabajo en 2013. Dado que esa legislación debería ajustarse a las características esenciales, tal vez resulte fácil obtener información a partir del proceso de seguimiento de la aplicación llevado a cabo por el Consejo de Estabilidad Financiera que indique los avances que se han hecho, particularmente con respecto a los aspectos transfronterizos de los nuevos regímenes. Una cuestión conexa podría ser la de saber en qué medida la labor realizada por el Consejo de Estabilidad Financiera y otras organizaciones abarca el tema, sobre todo en lo referente al establecimiento de mecanismos de reconocimiento y cooperación transfronterizos, ya sea aplicable a entidades financieras individuales o a grupos financieros y también la de saber si se justificaría que la CNUDMI realizara otros estudios. Tales estudios podrían ser de interés en futuras deliberaciones sobre el mandato del Grupo de Trabajo V, como ya se ha indicado, en la medida en que guarde relación con el tratamiento de los grupos en procedimientos de insolvencia transfronteriza.

Anexo

Lista de documentos

Grupo de los Veinte

03/2009 Working Group on Reinforcing International Cooperation and Promoting Integrity in Financial Markets (WG 2)

Grupo de los Treinta

1998 International Insolvencies in the Financial Sector, G30 Working Group, ISBN 1-56708-099-5; se puede consultar en www.group30.org/rpt_22.shtml

Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, Banco de Pagos Internacionales

Publicaciones que se pueden consultar en www.bis.org

08/2003 High-Level Principles for Cross-Border Implementation of the New Accord

09/2009 Informe y recomendaciones del Grupo de solución de problemas bancarios de carácter transfronterizo: documento de consulta

03/2010 Informe y recomendaciones del Grupo de solución de problemas bancarios de carácter transfronterizo: documento de consulta

Foro sobre la Estabilidad Financiera

04/2009 Principles for Cross-border Cooperation on Crisis Management. Se puede consultar en www.financialstabilityboard.org/publications/r_0904c.pdf

Consejo de Estabilidad Financiera

Estas publicaciones se pueden consultar en www.financialstabilityboard.org/publications

06/2010 Promoting global adherence to international cooperation and information exchange standards

07/2011 Effective resolution of systemically important financial institutions: recommendations and timelines - consultation document

10/2011 Key attributes of effective resolution regimes for financial institutions

11/2011 Effective resolution of systemically important financial institutions - overview of responses to the public consultation

11/2011 Policy Measures to Address Systematically Important Financial Institutions

Fondo Monetario Internacional (FMI)

04/09 (con el Banco Mundial): An overview of the legal, institutional and regulatory framework for bank insolvency

- 06/2010 Resolution of Cross-border Banks - a proposed framework for enhanced coordination. Se puede consultar en www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/061110.pdf

Unión Europea

- 10/2009 Comisión Europea: Comunicación sobre un régimen comunitario para la gestión transfronteriza de las crisis en el sector bancario COM (2009) 561
- 2009 Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión: An EU Framework for Cross-border Crisis Management in the Banking Sector (SEC 2009 (1407))
- 05/2010 Comisión Europea: Comunicación sobre los fondos de resolución bancaria COM (2010) 254
- 06/2010 Parlamento Europeo, Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: informe con recomendaciones a la Comisión en materia de gestión transfronteriza de las crisis en el sector bancario (A7-0213/2010) (informe Ferreira)
- 10/2010 Comisión Europea, Dotar a la UE de un marco para la gestión de crisis en el sector financiero COM (2010) 579 final
- 12/2010 Consejo Europeo (ECOFIN): Conclusiones a favor de un marco de la Unión para la prevención, gestión y resolución de crisis 17006/1/10
- 01/2011 Documento de trabajo de la Comisión Europea (DG Mercado Interior y Servicios): Technical Details of a Possible EU Framework for Bank Recovery and Resolution
- 05/2011 Comisión Europea, Overview of the results of the public consultation on technical details of a possible EU framework for bank resolution and recovery
- 05/2012 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, Medidas en favor de la estabilidad, el crecimiento y el empleo, COM(2012) 299 final; se puede consultar en http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/eccomm2012_es.pdf
- 06/2012 Comisión Europea: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms COM (2012) 280/3; Commission Staff Working Document Impact Assessment accompanying that document, SWD (2012) 166 final and summary of the impact assessment SWD (2012) 167 final

E. Nota de la Secretaría sobre el régimen de la insolvencia: asistencia y cooperación técnicas, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 42º período de sesiones

(A/CN.9/WG.V/WP.110)

[Original: inglés]

Introducción

1. En su 44º período de sesiones (2011), la Comisión destacó la importancia de la cooperación y asistencia técnicas que prestaba la Secretaría de la CNUDMI, considerando que la asistencia técnica en materia legislativa, en particular a los países en desarrollo, era una actividad no menos importante que la propia formulación de reglas uniformes. Se había observado que, si bien la CNUDMI había preparado diversos instrumentos legislativos, variaba mucho su grado de adopción por los Estados, por lo que tal vez debía prestarse especial atención al fomento de su adopción y uso¹.
2. En su 45º período de sesiones (2012), la Comisión señaló que solo se podría seguir atendiendo a las solicitudes de actividades de cooperación y asistencia técnicas de los Estados y las organizaciones regionales si se disponía de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos conexos. Señaló además que, pese a las gestiones realizadas por la Secretaría para solicitar nuevas donaciones, los recursos de que se disponía en el Fondo Fiduciario para Simposios de la CNUDMI eran muy limitados. Se observó que los delegados y los expertos de la CNUDMI tal vez podrían contribuir más al cumplimiento del mandato de esta, por ejemplo, ayudando a determinar quiénes eran los encargados de adoptar decisiones sobre la reforma del derecho mercantil².
3. Con ese trasfondo, se ha pedido a los Grupos de Trabajo que dediquen algún tiempo de sus períodos de sesiones a examinar posibles formas de promover la aplicación de los textos de la CNUDMI. En su 41º período de sesiones, celebrado en 2012, el Grupo de Trabajo sostuvo un debate oficioso sobre las actividades recientes realizadas por varios Estados parte para la promulgación y utilización de los textos de la Comisión relativos a la insolvencia. En el informe de ese período de sesiones se incluyó un breve resumen de ese debate (A/CN.9/742, párrs. 102 a 104).
4. Para facilitar las deliberaciones de su 42º período de sesiones (previsto para noviembre de 2012), el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las cuestiones siguientes, entre otras, y comunicar sus opiniones. En la medida en que el debate puede conducir a propuestas sobre actividades o trabajos posteriores de la Secretaría, cabe señalar que habría que ajustarse a las actuales limitaciones de recursos.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párrs. 253 y 254.*

² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 146.*

a) Los instrumentos de la CNUDMI relativos al régimen de la insolvencia se mencionan a menudo en la bibliografía sobre ese régimen y su reforma. En algunos casos, se señala que han establecido normas internacionales que se recomienda a los Estados aplicar o utilizar como referencia al revisar y modernizar sus regímenes de la insolvencia. En otros, se enumeran entre los muchos instrumentos de referencia que se hallan a disposición de los Estados; se les considera del mismo rango que los elaborados por otras organizaciones internacionales y no gubernamentales. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la forma en que podría ayudar a la Secretaría a promover mejor los textos de la CNUDMI sobre la insolvencia y difundir más ampliamente información sobre ellos;

b) En las resoluciones de la Asamblea General que respaldan los textos aprobados por la Comisión se solicita con frecuencia a la Secretaría que los señale a la atención de los Estados a fin de garantizar que se conozcan y difundan ampliamente. Aunque algunos textos, como las leyes modelo y las guías legislativas, van dirigidos principalmente a los Estados (los gobiernos y los legisladores), otros se han preparado pensando en los jueces y los profesionales en la materia. Esos textos podrían conocerse más si se promovieran de otro modo, por ejemplo entre los colegios y agrupaciones judiciales y otras instituciones de ese tipo en los países. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la manera en que podría ayudar a la Secretaría a determinar los medios apropiados de promover esos textos;

c) Los debates celebrados durante el 41º período de sesiones del Grupo de Trabajo pusieron de relieve información sobre las actividades de asistencia técnica realizadas por los Estados y las organizaciones internacionales en que se utilizaban los textos de la CNUDMI sobre la insolvencia. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si convendría difundir más información de ese tipo y, en caso afirmativo, la forma de hacerlo.

**F. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia
sobre la labor realizada en su 43º período de sesiones
(Nueva York, 15 a 19 de abril de 2013)**

(A/CN.9/766)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-4
II. Organización del período de sesiones	5-11
III. Deliberaciones y decisiones	12
IV. Interpretación y aplicación de determinados conceptos enunciados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses	13-54
A. Finalidad y origen de la Ley Modelo	14-16
B. Finalidad de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación	17
C. La Ley Modelo como vehículo de armonización del derecho	18
D. Características principales de la Ley Modelo	19-20
E. Observaciones a cada uno de los artículos	21-53
F. Asistencia de la Secretaría de la CNUDMI	54
V. Obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia	55-100
A. Proyectos de recomendación	56-75
B. Proyecto de comentario	76-100
VI. Finalización de la labor relacionada con el centro de los principales intereses y las obligaciones de los directores	101-102
VII. Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial	103
VIII. Aplicación de los restantes aspectos del mandato actual del Grupo de Trabajo ...	104-109
IX. Otros asuntos	110

I. Introducción

1. En su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión tuvo ante sí una serie de propuestas sobre la posible labor futura en relación con el régimen de la insolvencia (A/CN.9/WG.V/WP.93 y Add.1 a 6 y A/CN.9/582/Add.6). Esas propuestas se habían examinado en el 38º período de sesiones del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) (véase A/CN.9/691, párrs. 99 a 107) junto con una recomendación sobre posibles temas presentada a la Comisión

(A/CN.9/691, párr. 104). En otro documento (A/CN.9/709), presentado después de ese período de sesiones del Grupo de Trabajo V, se incluía material complementario a la propuesta de Suiza que figuraba en el documento A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5.

2. Tras las correspondientes deliberaciones, la Comisión hizo suya la recomendación del Grupo de Trabajo V de que se emprendieran actividades sobre tres temas relacionados con la insolvencia: a) la interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses; b) las responsabilidades y obligaciones de los directores en situaciones de insolvencia y preinsolvencia, temas que eran ambos de importancia en la actualidad; y c) el material judicial relativo a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza. En su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión finalizó y aprobó la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial.

3. En su 39º período de sesiones, celebrado en 2010, el Grupo de Trabajo V inició su examen de esos tres temas basándose en notas preparadas por la Secretaría (A/CN.9/WG.V/WP.95 y Add.1 y A/CN.9/WG.V/WP.96). Las decisiones y conclusiones del Grupo de Trabajo figuran en el documento A/CN.9/715. El Grupo de Trabajo siguió examinando los temas a) y b) en su 40º período de sesiones, celebrado en 2011, basándose en notas preparadas por la Secretaría (A/CN.9/WG.V/WP.99, 100 y 101), en su 41º período de sesiones, celebrado en 2012, basándose asimismo en notas preparadas por la Secretaría (A/CN.9/WG.V/WP.103 y Add.1, 104 y 105) y en su 42º período de sesiones, celebrado en 2012, basándose también en notas preparadas por la Secretaría (A/CN.9/WG.V/WP.107 y 108).

4. En su 43º período de sesiones, que tuvo lugar en junio de 2010, la Comisión examinó una propuesta de estudio de la viabilidad de un instrumento internacional de resolución transfronteriza de casos de insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5 y A/CN.9/709, párr. 5). Se acordó que la Secretaría preparara un informe amplio sobre todas o algunas de las cuestiones planteadas en la propuesta. En su 42º período de sesiones, celebrado en 2012, el Grupo de Trabajo examinó por primera vez ese tema basándose en una nota preparada por la Secretaría (A/CN.9/WG.V/WP.109). Las deliberaciones y conclusiones del Grupo de Trabajo sobre el tema figuran en el informe de ese período de sesiones (A/CN.9/763, párrs. 95 y 96).

II. Organización del período de sesiones

5. El Grupo de Trabajo V, compuesto por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 43º período de sesiones del 15 al 19 de abril de 2013 en Nueva York. Al período de sesiones asistieron representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Croacia, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, India, Israel, Italia, Japón, Kenya, México, Nigeria, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Tailandia, Ucrania y Uganda.

6. Asistieron al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Dinamarca, Guatemala, Hungría, Indonesia, Kuwait, Lituania, Nicaragua, Omán, Polonia, Qatar, República Dominicana y Suiza.
7. Asistieron también al período de sesiones los siguientes Estados no miembros: Santa Sede.
8. Asimismo, asistieron al período de sesiones observadores de las siguientes organizaciones internacionales:
 - a) *Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas*: Banco Mundial;
 - b) *Organizaciones intergubernamentales invitadas*: Banco Islámico de Desarrollo;
 - c) *Organizaciones internacionales no gubernamentales invitadas*: American Bar Association (ABA), Asociación Europea de Estudiantes de Derecho (ELSA), Asociación Internacional de Abogados, Business Recovery and Insolvency Practitioners Association of Nigeria (BRIPAN), Confederación Internacional de Mujeres Especializadas en Insolvencia y Reestructuración (IWIRC), Federación Interamericana de Abogados (FIA), INSOL International (INSOL), International Insolvency Institute (III), Inter-Pacific Bar Association, New York State Bar Association (NYSBA) y Unión Internacional de Abogados (UIA).
9. El Grupo de Trabajo eligió la siguiente Mesa:

Presidente: Sr. Wisit Wisitsora-At (Tailandia)

Relatora: Sra. María del Pilar Escobar Pacas (El Salvador)
10. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí los siguientes documentos:
 - a) Programa provisional anotado (A/CN.9/WG.V/WP.111);
 - b) Una nota de la Secretaría sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos enunciados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses (A/CN.9/WG.V/WP.112);
 - c) Una nota de la Secretaría sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia (A/CN.9/WG.V/WP.113);
 - d) Una nota de la Secretaría sobre el centro de los principales intereses en el contexto de grupos de empresas (A/CN.9/WG.V/WP.114); y
 - e) Una nota de la Secretaría sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia en el contexto de grupos de empresas (A/CN.9/WG.V/WP.115).
11. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:
 1. Apertura del período de sesiones.
 2. Elección de la Mesa.
 3. Aprobación del programa, observando que no había ningún informe sobre la insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas.

4. Examen de a) la interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses; b) las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia; c) el centro de los principales intereses en el contexto de grupos de empresas; y d) las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia en el contexto de grupos de empresas.
5. Examen de las actualizaciones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial.
6. Otros asuntos.
7. Aprobación del informe.

III. Deliberaciones y decisiones

12. El Grupo de Trabajo deliberó sobre los temas siguientes: a) la forma de dar orientación sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses; b) las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia; c) el centro de los principales intereses en el contexto de grupos de empresas; y d) las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia en el contexto de los grupos de empresas; las deliberaciones se basaron en los documentos A/CN.9/WG.V/WP.112, A/CN.9/WG.V/WP.113, A/CN.9/WG.V/WP.114 y A/CN.9/WG.V/WP.115, respectivamente. A continuación se recogen las deliberaciones que el Grupo de Trabajo mantuvo sobre esos temas y las decisiones que adoptó al respecto.

IV. Interpretación y aplicación de determinados conceptos enunciados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses

13. El Grupo de Trabajo inició su examen de las propuestas de revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza, que figuraban en el documento A/CN.9/WG.V/WP.112.

A. Finalidad y origen de la Ley Modelo

14. El Grupo de Trabajo acordó suprimir las palabras “(denominados ‘Estados promulgantes’)” que figuraban en la segunda oración, dado que en la nota a pie de página del párrafo 3 a) se explicaba la utilización de las palabras “Estado promulgante”. También acordó revisar la última oración del párrafo 2 de modo que dijera lo siguiente: “Al aprobar legislación basada en la Ley Modelo, los Estados reconocen que para cumplir las normas internacionalmente reconocidas tal vez tengan o hayan tenido que modificar algunas de sus leyes sobre insolvencia”.

15. Además, se acordó que, con respecto a las palabras del final de la primera oración del encabezamiento del párrafo 3, se sustituirían las palabras “cierto grado de armonización” por las palabras “y promueven un enfoque homogéneo de la insolvencia transfronteriza”.

16. Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 1, 2, 3, 3A, 18, 4, 5, 6 y 7 tal como estaban redactados.

B. Finalidad de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación

17. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 9 y 10 tal como estaban redactados.

C. La Ley Modelo como vehículo de armonización del derecho

18. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 20 y 21 tal como estaban redactados.

D. Características principales de la Ley Modelo

19. Se sugirió que bajo el encabezamiento “Cooperación y coordinación” se hiciera referencia a la cooperación y coordinación de los procedimientos de insolvencia en el contexto de los grupos de empresas. Observando el párrafo 9 de la introducción del documento A/CN.9/WG.V/WP.112, el Grupo de Trabajo acordó volver a tratar esta cuestión cuando hubiera terminado de examinar el proyecto de texto (véase el párrafo 52 *infra*).

20. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 49A a 49D, 37A a 37H, 32, y 33A a 33G tal como estaban redactados.

E. Observaciones a cada uno de los artículos

Preámbulo

21. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del párrafo 54 tal como estaba redactado.

Utilización del término “insolvencia”

22. El Grupo de Trabajo examinó la propuesta de insertar al final del párrafo 51 la siguiente oración: “Cuando el procedimiento se haya abierto con varios fines, entre ellos el de liquidar una entidad solvente, se le aplicará el artículo 2, inciso a), de la Ley Modelo únicamente si el deudor es insolvente o está en una situación de graves apuros financieros.” En relación con esa propuesta se señaló que en la nota del párrafo 23B se explicaba el significado de la expresión “liquidación”. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo aprobó la propuesta. Durante su examen, el Grupo de Trabajo señaló la necesidad de hacer un uso coherente de la expresión “insolvencia o

situaciones de graves apuros financieros” en todo el texto. Tras esa modificación, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del párrafo 51.

23. Una propuesta conexa, que no recibió apoyo suficiente, fue la de revisar la última oración del párrafo 24B de modo que se sustituyeran las palabras “para una entidad jurídica solvente que no busque reestructurar sus asuntos financieros sino disolverse” por las palabras “para que una entidad jurídica solvente se disuelva”, a fin de que se mantuviera la coherencia con el párrafo 51 revisado.

24. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del párrafo 51A tal como estaba redactado.

“Estado”

25. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del párrafo 56 tal como estaba redactado.

Capítulo I. Disposiciones generales - artículos 1 a 8

Artículo 1. Ámbito de aplicación

26. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 59 y 65 tal como estaban redactados.

Artículo 2. Definiciones

Incisos a) a f)

27. El Grupo de Trabajo acordó que se insertaran las palabras “o poseía” después de las palabras “un procedimiento extranjero posee” en la última oración del párrafo 23.

28. Tras esa modificación, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 68, 68A, 71, 72, 23 a 23C, 24 a 24G, 70, 31 a 31C, y 73 a 75B tal como estaban redactados.

Artículo 3

29. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del párrafo 78 tal como estaba redactado.

Artículos 5 y 8

30. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 84 y 91 tal como estaban redactados.

Capítulo II. Acceso de los representantes y acreedores extranjeros a los tribunales del Estado

Artículos 9 a 12

31. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 93, 96, 98, 101 y 102 tal como estaban redactados.

Capítulo III. Reconocimiento de un procedimiento extranjero y medidas otorgables

Artículo 15

32. El Grupo de Trabajo acordó sustituir, en la versión inglesa, la palabra “fast” en la segunda oración del párrafo 112 por la palabra “expedited”. Tras esa modificación, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 112, 119 y 120 tal como estaban redactados.

Artículo 16. Presunciones relativas al reconocimiento

Párrafo 1

33. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 122 a 122B tal como estaban redactados.

Párrafo 3

34. Con respecto al párrafo 123B, el Grupo de Trabajo acordó sustituir la palabra “Probablemente” por la palabra “Posiblemente” en la segunda oración.

35. El Grupo de Trabajo examinó varias propuestas de revisión del párrafo 123C para aclarar que el tribunal seguía teniendo la obligación de determinar por sí mismo la ubicación del centro de los principales intereses del deudor independientemente de si se hubiera alegado o no que el centro de los principales intereses no era el domicilio social. Tras las correspondientes deliberaciones, no hubo apoyo suficiente en el Grupo de Trabajo para aprobar ninguna de las propuestas.

36. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 123A a 123C tal como estaban redactados.

Centro de los principales intereses

37. El Grupo de Trabajo acordó suprimir la palabra “siempre” en la quinta oración del párrafo 123D. También acordó suprimir en la penúltima oración las palabras “Cuando no se tenga la certidumbre de que el domicilio social del deudor es el centro de sus principales intereses” y sustituirlas por las palabras “En esas circunstancias”. Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del párrafo 123D.

Factores pertinentes para determinar el centro de los principales intereses

38. El Grupo de Trabajo acordó reformular la segunda oración del párrafo 123F de modo que dijera lo siguiente: “Esos factores son el lugar: a) en que se lleve a cabo la administración central del deudor, y b) que sea fácil de averiguar para los acreedores”. También acordó añadir las palabras “que sea fácil de averiguar para los acreedores” al final de la última oración del párrafo 123G.

39. Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 123F, 123G y 123I tal como estaban redactados.

Traslado del centro de los principales intereses

40. Tras examinar la propuesta de suprimir los párrafos 123K y M, el Grupo de Trabajo acordó que se mantuvieran los párrafos y aprobó el contenido de estos tal como estaban redactados. El Grupo de Trabajo procedió a examinar la nota 22 del párrafo 123K y acordó que la segunda oración terminara después de la palabra “terceros” tras suprimirse tanto las palabras “o haberse llevado a cabo aprovechando información confidencial o por motivos subjetivos” como los corchetes de la nota.

*Artículo 17. Resolución de reconocimiento de un procedimiento extranjero**Párrafo 1*

41. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 124 a 124C tal como estaban redactados.

*Párrafo 2**Momento de la determinación del centro de los principales intereses y el establecimiento*

42. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 128A a D tal como estaban redactados.

Abuso del proceso

43. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 123J y 123L tal como estaban redactados.

Párrafos 3 y 4

44. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 125 a 131 tal como estaban redactados.

*Artículo 18. Información subsiguiente**Incisos a) y b)*

45. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 133 y 134 tal como estaban redactados.

*Artículo 19. Medidas otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero**Párrafos 1 a 4*

46. Se aprobó el contenido de los párrafos 135 a 140 tal como estaban redactados.

Artículo 20. Efectos del reconocimiento de un procedimiento extranjero principal

47. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 141, 143, 144 a 146, 149, y 151 a 153 tal como estaban redactados.

Artículo 21. Medidas otorgables a partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero

48. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 154, 156, 158 y 160 tal como estaban redactados.

Artículo 22. Protección de los acreedores y de otras personas interesadas

49. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 162 a 164 tal como estaban redactados.

Artículo 23. Acciones de impugnación de actos perjudiciales para los acreedores

50. Se aprobó el contenido de los párrafos 165 a 167 tal como estaban redactados.

Artículo 24. Intervención de un representante extranjero en procedimientos que se sigan en este Estado

51. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del párrafo 170 tal como estaba redactado.

Capítulo IV. Cooperación con tribunales y representantes extranjeros

52. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 173A, 181, 183 y 183A tal como estaban redactados, con la adición del siguiente texto a la nota del párrafo 183A: “La Ley Modelo se aplica a deudores individuales, ya sean personas jurídicas o físicas. Sin embargo, la tercera parte de la Guía legislativa sobre el régimen de la insolvencia se refiere al tratamiento de los grupos de empresas en los procedimientos de insolvencia y las recomendaciones 240 a 254 se centran en la cooperación y comunicación para facilitar el funcionamiento de los procedimientos de insolvencia transfronteriza cuando se refieran a miembros de un grupo de empresas.” En apoyo de esa adición, se señaló que pese a que la Ley Modelo no se aplicaba específicamente a los grupos de empresas, la nota debería incluirse a fin de señalar la labor de la CNUDMI en relación con los grupos de empresas (véase el párrafo 19 *supra*).

Capítulo V. Procedimientos paralelos

53. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 184 a 186, 187A, 188 y 197 tal como estaban redactados.

F. Asistencia de la Secretaría de la CNUDMI

54. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 201 y 202 tal como estaban redactados.

V. Obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia

55. El Grupo de Trabajo reanudó su examen del tema de las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia basándose en el documento

A/CN.9/WG.V/WP.113, para lo cual se centró en primer lugar en los proyectos de recomendación.

A. Proyectos de recomendación

Recomendaciones 1 y 2 - Las obligaciones

Finalidad de las disposiciones legislativas

56. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la cláusula relativa a la finalidad en los proyectos de recomendación 1 y 2 tal como estaba redactada.

Contenido de las disposiciones legislativas

57. Se propuso que se modificara la secuencia de las recomendaciones colocando la recomendación 1 después de las recomendaciones 3 y 4 para no tener que incluir remisiones en la recomendación 1, pero esa propuesta no recibió apoyo. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del proyecto de recomendación 1 tal como estaba redactado, tras suprimir los corchetes de las palabras “[de acuerdo con]” y mantener el texto.

58. El Grupo de Trabajo acordó que se sustituyeran las palabras “no permitir que la empresa se comprometa a concertar determinados tipos de operaciones” por las palabras “no permitir que la empresa se comprometa con determinados tipos de operaciones” en el inciso a) del proyecto de recomendación 2.

59. El Grupo de Trabajo acordó que el inciso b) del proyecto de recomendación 2 comenzara con las palabras “Iniciar o solicitar el inicio de”, en lugar de con la palabra “Iniciar”, y que se suprimieran las palabras “cuando sea apropiado hacerlo o cuando lo exija la legislación nacional” al final de la oración.

60. Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los proyectos de recomendación 1 y 2 tal como estaban redactados.

Recomendación 3 - ¿Cuándo nacen las obligaciones?

Finalidad de las disposiciones legislativas

61. El Grupo de Trabajo acordó que se sustituyeran las palabras “deberían nacer las obligaciones” por las palabras “nacen las obligaciones”, al final de la cláusula sobre la finalidad, y que se suprimieran los corchetes. Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la cláusula sobre la finalidad tal como estaba redactada.

Contenido de las disposiciones legislativas

62. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del proyecto de recomendación 3 tal como estaba redactado.

Recomendación 4 - Personas en quienes recaen las obligaciones**Finalidad de las disposiciones legislativas**

63. El Grupo de Trabajo acordó que se sustituyeran las palabras “determinar a quiénes deben aplicarse las obligaciones” por las palabras “determinar en quiénes recaen las obligaciones de la recomendación 1”, al final de la cláusula sobre la finalidad, y que se suprimieran los corchetes. Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la cláusula sobre la finalidad tal como estaba redactada.

Contenido de las disposiciones legislativas

64. El Grupo de Trabajo acordó que se sustituyeran las palabras “la persona en quien recaen las obligaciones” por las palabras “la persona en quien recaen las obligaciones de la recomendación 1”. Tras esa modificación, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del proyecto de recomendación 4 tal como estaba redactado.

Recomendaciones 5 y 6 - Responsabilidad**Finalidad de las disposiciones legislativas**

65. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la cláusula sobre la finalidad tal como estaba redactada, tras suprimir los corchetes.

Contenido de las disposiciones legislativas

66. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del proyecto de recomendación 5 tal como estaba redactado.

67. No recibió apoyo suficiente la propuesta de fusionar los proyectos de recomendación 5 y 6 añadiendo al final del proyecto de recomendación 5 las palabras “pero únicamente en la medida de las pérdidas y los daños que ha causado el incumplimiento” y suprimiendo el proyecto de recomendación 6. El Grupo de Trabajo opinó que la formulación actual quedaba más clara y que era mejor tratar por separado cada una de las dos cuestiones a las que hacían referencia los proyectos de recomendación. El Grupo de Trabajo acordó suprimir los corchetes y la palabra “por” y mantener las palabras “derivada del” sin los corchetes. Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de recomendación 6 tal como estaba redactado.

Recomendaciones 7 a 11

68. Se apoyó la propuesta de trasladar el proyecto de recomendación 7 (junto con los párrafos 31 a 47 del comentario) a la sección D, relativa a la responsabilidad, dado que se refería a la responsabilidad y no a la ejecución de las responsabilidades de los directores. Como consecuencia, se acordó también ajustar la cláusula sobre la finalidad relativa a las recomendaciones 5 y 6 para añadir un nuevo inciso b) que

dijera, por ejemplo, “determinar las excepciones que podrán oponerse a una alegación de incumplimiento de las obligaciones”, de modo que el antiguo inciso b) se convirtiera en inciso c). Además, se acordó cambiar el título del encabezamiento de la sección E del comentario por el de “Ejecución de las responsabilidades de los directores”.

Finalidad de las disposiciones legislativas

69. El Grupo de Trabajo acordó revisar la frase inicial de la cláusula sobre la finalidad, de modo que en lugar de “ejecución de las obligaciones” dijera “ejecución de las responsabilidades de los directores”, y suprimir los corchetes. Tras esa modificación, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la cláusula sobre la finalidad tal como estaba redactada.

Recomendación 7 - Elementos de la responsabilidad y excepciones

Contenido de las disposiciones legislativas

70. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del proyecto de recomendación 7 tal como estaba redactado.

Recomendación 8 - Recursos

Contenido de las disposiciones legislativas

71. El Grupo de Trabajo acordó que se suprimieran las palabras “[como indemnización por ese incumplimiento]”. Se opusieron reservas con respecto a la segunda oración, en particular ante el riesgo de que desincentivara a los directores de hacer préstamos a empresas en el período cercano a la insolvencia a fin de tratar de evitar la insolvencia y tras el inicio de un procedimiento de insolvencia a fin de facilitar la reorganización, así como en lo que respecta a su relación con la recomendación 100 de la Guía Legislativa. Después de largas deliberaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de recomendación 8 tras suprimir la segunda oración.

Recomendación 9 - Sustanciación de la demanda por incumplimiento de la obligación

Contenido de las disposiciones legislativas

72. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del proyecto de recomendación 9 tal como estaba redactado.

Recomendaciones 10 y 11 - Financiación de las demandas por incumplimiento de la obligación

Contenido de las disposiciones legislativas

73. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los proyectos de recomendación 10 y 11 tal como estaban redactados.

Recomendación 12 - Medidas adicionales

Contenido de las disposiciones legislativas

74. El Grupo de Trabajo recordó el examen del proyecto de recomendación que había realizado en su período de sesiones anterior. Se expresaron varias dudas acerca de la conveniencia de incluir el proyecto de recomendación, dado que no podía considerarse parte del régimen relativo a la insolvencia propiamente dicho, sino que pertenecía al ámbito del derecho de sociedades o del derecho penal, y podría disuadir a los directores de permanecer en los consejos de administración de empresas que se encontraran en apuros financieros para ayudarlas en su reorganización. Otra opinión fue que el proyecto de recomendación 12 tenía por objeto ampliar al contexto de las quiebras de empresas los tipos de medidas que se aplicaban en diversas jurisdicciones en el contexto de los regímenes de la insolvencia de las personas físicas, y que, en todo caso, el proyecto de recomendación era simplemente permisivo y no pretendía sancionar sino alentar un comportamiento adecuado. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo acordó mantener las palabras “de un resarcimiento”, suprimiendo los corchetes, y suprimir las palabras “[por daños y perjuicios]”. Tras esa modificación, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del proyecto de recomendación 12 tal como estaba redactado.

Propuesta de una recomendación adicional

75. El Grupo de Trabajo escuchó una propuesta relativa a la especificación de los requisitos para entablar acciones contra un director por el incumplimiento de las obligaciones examinadas en el proyecto de recomendación 1. La propuesta iba dirigida a evitar casos como los ocurridos en algunos Estados en los que las acciones entabladas contra un director habían retrasado innecesariamente la conclusión de un procedimiento de insolvencia. Los requisitos propuestos fueron que la persona que deseara entablar acciones contra un director demostrara que este disponía de bienes suficientes para cumplir con un posible fallo en su contra y que hubiera una probabilidad razonable de que la demanda prosperara en cuanto al fondo, de forma que se justificara la adopción de medidas cautelares para asegurar la conservación de los bienes del director. El Grupo de Trabajo señaló que, si bien esta era una cuestión importante en algunos Estados, en muchos otros el inicio de tales acciones no suponía un retraso en la conclusión del procedimiento de insolvencia y, en todo caso, la obligación de diligencia del representante de la insolvencia exigiría que se analizaran las probabilidades de que esas acciones prosperaran en beneficio de la masa de la insolvencia. Si bien no hubo apoyo suficiente a la propuesta de que se incluyera una nueva recomendación en el sentido propuesto, el Grupo de Trabajo acordó que se podría hacer referencia al tema en el comentario (véase el párrafo 99 *infra*).

B. Proyecto de comentario

Introducción y finalidad de esta [parte]

76. El Grupo de Trabajo aprobó la siguiente revisión del párrafo 1:

“Esta [parte] se centra en las obligaciones que se podrían imponer a los responsables de adoptar decisiones con respecto a la administración de una

empresa cuando esa empresa se enfrenta a una insolvencia inminente o la insolvencia se hace inevitable. El propósito de imponer esas obligaciones, que serían exigibles una vez que se hubiera iniciado el procedimiento de insolvencia, es proteger los intereses legítimos de los acreedores y demás interesados y servir de incentivo para que se actúe con prontitud para minimizar los efectos de los apuros financieros que atraviesa la empresa. La constitución de una junta directiva es un factor importante para hacer frente a esos problemas. Cuando una empresa tiene directores independientes que no tienen una participación considerable en el capital social y no representan a los accionistas, tales directores pueden no tener acceso a información en la misma medida en que pueden tenerlo los directores internos. La responsabilidad de los directores internos e independientes puede ser distinta, según las circunstancias del caso.”

77. El Grupo de Trabajo convino en trasladar las tres últimas oraciones del texto del párrafo 1 aprobado *supra* al final del párrafo 35.

78. El Grupo de Trabajo acordó eliminar los corchetes del párrafo 2 y aprobó el texto tal como estaba redactado.

1. Contexto

79. El Grupo de Trabajo aprobó los párrafos 1 a 15 tal como estaban redactados, lo que incluyó suprimir los corchetes del párrafo 2 y mantener el texto.

2. Elementos de las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia

La naturaleza de las obligaciones

80. El Grupo de Trabajo aprobó los párrafos 16 a 18 tal como estaban redactados.

81. Tras suprimir las palabras iniciales: “Salvo en aquellos regímenes en que los directores tienen la obligación de informar o de hacer declaraciones oficiales”, el Grupo de Trabajo aprobó el párrafo 19 tal como estaba redactado.

82. El Grupo de Trabajo aprobó el párrafo 20 con los siguientes cambios:

a) Se mantendría el texto y se suprimirían los corchetes de los incisos d), f) y j);

b) Se sustituirían las palabras “tener también en cuenta” por las palabras “tener en cuenta” en la segunda oración del inciso g); y

c) Se sustituirían las palabras “Un ejemplo” por la palabra “Ejemplos” en la segunda oración de la nota del inciso h).

83. El Grupo de Trabajo convino en eliminar los corchetes de los párrafos 21 y 21A y aprobó ambos párrafos tal como estaban redactados.

Cuándo nacen las obligaciones: el período cercano a la insolvencia

84. El Grupo de Trabajo aprobó los párrafos 22, 23 y 24 tal como estaban redactados.

85. El Grupo de Trabajo acordó que se mantuviera la segunda oración del párrafo 25, sin los corchetes, y que se revisara la quinta oración de modo que dijera lo

siguiente: “Esencialmente esto requiere evaluar la actuación del director en función del conocimiento que un director razonablemente competente habría o debería haber tenido en las circunstancias del caso”. Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el párrafo 25 tal como estaba redactado.

86. El Grupo de Trabajo aprobó un nuevo párrafo 25A cuyo texto era el siguiente: “Las recomendaciones no impiden que los Estados impongan a los directores responsabilidades que puedan ser exigibles al margen de un procedimiento de insolvencia cuando, debido a la falta de activos para sufragar los costos de un procedimiento, se deniega la apertura de un procedimiento de insolvencia”.

Determinación de las partes en las que recaen las obligaciones

87. El Grupo de Trabajo acordó suprimir la nota del párrafo 26. Tras esa modificación, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 26 a 29 tal como estaban redactados.

Responsabilidad

88. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 30 y 31 tal como estaban redactados.

89. El Grupo de Trabajo acordó suprimir la última oración del párrafo 32 y aprobó el resto del párrafo 32 tal como estaba redactado.

90. El Grupo de Trabajo acordó mantener las oraciones segunda y tercera, suprimiendo los corchetes, y aprobó el contenido del párrafo 33 tal como estaba redactado.

91. El Grupo de Trabajo acordó que se suprimiera la primera oración del párrafo 34 y se sustituyeran las palabras “Los regímenes que adoptan este enfoque” al principio de la segunda oración por las palabras “Otros regímenes”. Además, el Grupo de Trabajo acordó que se añadieran las palabras “en que los directores no obtienen o estudian las cuentas de gestión;” antes de las palabras “en que los directores descuidan la debida administración financiera de la empresa”, y que se revisara el texto siguiente de modo que dijera “en que no adoptan medidas preventivas contra riesgos claramente previsibles; o en que la mala gestión del personal por los directores da lugar a malestar y huelgas”. Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del párrafo 34 tal como estaba redactado.

92. El Grupo de Trabajo acordó suprimir los corchetes del párrafo 35 y sustituir la primera oración por el texto siguiente: “Para determinar si un director ha incumplido sus obligaciones es necesario examinar los hechos en cuanto a su conducta con respecto al deudor en el período previo a la apertura del procedimiento de insolvencia”. El Grupo de Trabajo observó que ya había acordado en el curso del periodo de sesiones (véase el párr. 77 *supra*) trasladar las tres últimas oraciones del texto del párrafo 1 al final del párrafo 35.

93. Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del párrafo 35.

94. El Grupo de Trabajo suprimió los corchetes del párrafo 36 y aprobó el contenido del párrafo tal como estaba redactado.

Ejecución de las responsabilidades de los directores

95. El Grupo de Trabajo acordó mantener el texto y suprimir los corchetes del párrafo 41 y, tras esa modificación, aprobó el contenido de los párrafos 37 a 41 tal como estaban redactados.

96. El Grupo de Trabajo acordó mantener la palabra “Varios” sin los corchetes y suprimir la palabra “[Muchos]” en los párrafos 42 y 47; suprimir la última oración del párrafo 43; y suprimir los corchetes de la segunda oración del párrafo 48. Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 42 a 48.

97. El Grupo de Trabajo acordó suprimir las palabras “en determinadas circunstancias, por ejemplo” en la segunda oración del párrafo 51 y suprimir los corchetes de la tercera oración del mismo párrafo. Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 49 a 51.

98. El Grupo de Trabajo acordó sustituir la segunda oración del párrafo 52 por el siguiente texto: “Dependiendo de la ley relativa a la insolvencia que sea aplicable, el representante de la insolvencia puede interponer acciones contra un director en beneficio de la masa de la insolvencia, si se autorizan tales acciones. Si lo permite la ley relativa a la insolvencia, un acreedor puede interponer acciones contra un director en beneficio de la masa de la insolvencia si no lo hace el representante de la insolvencia. En algunos Estados, y según la ley relativa a la insolvencia que sea aplicable, un acreedor puede interponer acciones contra un director en beneficio propio. Todas esas acciones dependerán de que la conducta que se esté examinando haya ocurrido en el período cercano a la insolvencia.” Tras esa modificación, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 52 a 54.

99. El Grupo de Trabajo acordó sustituir el párrafo 55 por el siguiente texto: “Las acciones entabladas contra directores por incumplimiento de sus obligaciones pueden representar un activo importante de la masa de la insolvencia y contribuir a que los acreedores obtengan mayores beneficios. Ahora bien, en muchas jurisdicciones la duración de tales acciones impide concluir el procedimiento de insolvencia y proceder a la distribución final de los beneficios. Por tanto, es aconsejable que el representante de la insolvencia, antes de interponer acciones contra un director, tenga en cuenta las probabilidades de que tales acciones prosperen, así como otras circunstancias, como la capacidad del director de responder en caso de que deba indemnizar por daños y perjuicios, el alcance de la cobertura del seguro que tenga el director y los efectos de tales acciones sobre la duración del procedimiento de insolvencia”.

100. El Grupo de Trabajo acordó suprimir los corchetes de la segunda oración del párrafo 57 y revisar la cuarta oración de modo que dijera lo siguiente: “Cuando el demandante es una parte distinta del representante de la insolvencia que actúa en favor de los intereses colectivos de los acreedores, el costo de comenzar esas actuaciones puede recuperarse de la indemnización que se pague.” Tras esas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de los párrafos 56 y 57.

VI. Finalización de la labor relacionada con el centro de los principales intereses y las obligaciones de los directores

101. Tras cinco períodos de sesiones en los que se llevaron a cabo exhaustivos estudios, análisis y deliberaciones (entre diciembre de 2010 y abril de 2013), el Grupo de Trabajo comunica a la Comisión que ha concluido sustancialmente su labor sobre las partes de su mandato actual relacionadas con lo siguiente: a) la revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza en lo que respecta a determinados aspectos relacionados con el centro de los principales intereses y b) las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia (véanse los documentos A/CN.9/WG.V/WP.112 y 113, respectivamente). Con respecto a la labor sobre el tema b), el Grupo de Trabajo recomienda que ese texto se apruebe como cuarta parte de la Guía legislativa sobre el régimen de la insolvencia.

102. El Grupo de Trabajo solicitó a la Secretaría que distribuyera los dos proyectos de texto a los Estados y las organizaciones internacionales para que tuvieran esa información y formularan observaciones al respecto, y señaló que, aunque sería aconsejable, tal vez no sería posible traducir las observaciones recibidas para información de la Comisión.

VII. Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial

103. El Grupo de Trabajo señaló la versión actualizada de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial preparada por la Secretaría, en consulta con los expertos, de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión en 2011 por la que había aprobado ese texto. El Grupo de Trabajo expresó su aprecio y apoyo a la labor de actualización de la Perspectiva Judicial para que siguiera siendo vigente, y señaló lo útil que resultaba el texto para los jueces y para la difusión de información sobre las mejores prácticas más allá de los Estados que habían incorporado la Ley Modelo a su derecho interno.

VIII. Aplicación de los restantes aspectos del mandato actual del Grupo de Trabajo

104. El Grupo de Trabajo recordó las deliberaciones celebradas en su 42º período de sesiones sobre dos cuestiones que había planteado la Comisión en su 45º período de sesiones respecto a si el mandato del Grupo de Trabajo en relación con el centro de los principales intereses abarcaba aspectos relativos a los grupos de sociedades y, de ser así, cuándo debía examinar el tema el Grupo de Trabajo. En cuanto al alcance de su mandato en relación con el centro de los principales intereses, el Grupo de Trabajo había señalado que era necesario examinar los aspectos de esa cuestión relacionados con los grupos de sociedades, ya que la mayor parte de la actividad comercial se llevaba a cabo por medio de esos grupos. El Grupo de Trabajo también había observado la descripción del mandato que figuraba en el párrafo 10 del documento A/CN.9/WG.V/WP.107 y había señalado que, en su

redacción original, la intención era abarcar la cuestión del centro de los principales intereses en el contexto de los grupos de sociedades.

105. El Grupo de Trabajo recordó también que había convenido en que el tema se examinaría después de que se introdujeran las revisiones propuestas de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza en relación con el centro de los principales intereses de deudores individuales. En lo que respecta a las cuestiones relativas a los directores de empresas pertenecientes a un grupo de sociedades, el Grupo de Trabajo recordó que había convenido en que, si bien el tema planteaba cuestiones difíciles y complejas, particularmente en cuanto a los aspectos que vinculaban la insolvencia y el derecho de sociedades, la posibilidad de una futura labor al respecto merecía examinarse con suma atención. El Grupo de Trabajo había convenido en que, una vez que hubiera terminado su examen de las recomendaciones sobre las obligaciones de los directores y el comentario correspondiente, podría plantearse si abordar o no las cuestiones que podrían ser pertinentes en el contexto de los grupos de sociedades. Para facilitar esas deliberaciones, se había solicitado a la Secretaría que presentara información complementaria, en particular sobre los distintos enfoques y soluciones nacionales que podrían servir de base para el examen del Grupo de Trabajo.

106. Una vez concluida su labor sobre ambos temas, el Grupo de Trabajo pasó a ocuparse de los grupos de sociedades y de los documentos A/CN.9/WG.V/WP.114 y 115, junto con la parte de su mandato relacionada con la posible elaboración de una ley modelo o disposiciones modelo sobre el régimen de la insolvencia en que se regularan determinadas cuestiones del derecho internacional de la insolvencia, como las relativas a la jurisdicción, el acceso a los tribunales extranjeros y el reconocimiento de los procedimientos extranjeros, de un modo que no impidiera preparar una convención¹.

107. El Grupo de Trabajo celebró un debate general sobre las cuestiones que se habían planteado con respecto a los grupos de sociedades y las relativas a la parte restante del mandato encomendado por la Comisión.

108. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en que aún no había concluido su labor relativa a la aplicación del mandato encomendado por la Comisión y que aún quedaban cuestiones pendientes de las que debía ocuparse antes de que este se agotara. Además, el Grupo de Trabajo reconoció que aún no estaba claro cuál era el modo más indicado de cumplir esa parte del mandato. El Grupo de Trabajo escuchó una propuesta de celebración de un coloquio para examinar el modo en que podía cumplir la parte restante del mandato y el tipo de instrumento más adecuado para hacerlo, así como para determinar posibles temas de los que cabría ocuparse en el futuro. El Grupo de Trabajo convino en que un coloquio de esas características podría ser útil; no obstante, la sugerencia de que se celebrara en lugar de los periodos de sesiones del Grupo de Trabajo necesarios para concluir el mandato otorgado por la Comisión no atrajo un apoyo suficiente. Varias delegaciones sugirieron que se procurara obtener la aprobación de la Comisión para cualesquiera proyectos futuros, pero esa opinión no logró apoyo suficiente.

¹ Véase la propuesta conexas de la Unión Internacional de Abogados (UIA), relativa a la posibilidad de preparar una convención, a la que se hace referencia en A/CN.9/686, párrs. 127 a 130.

109. Además de los temas relacionados con la parte restante del mandato, se mencionaron los siguientes temas de que cabría ocuparse en el futuro, reconociendo que habría de solicitarse a la Comisión un mandato adicional al respecto: normas del derecho internacional privado aplicables en los procedimientos de insolvencia, especialmente en lo que respecta a los grupos de sociedades; eficacia de los instrumentos actuales a la luz de la crisis financiera mundial, en particular, las disposiciones de la guía legislativa relativas a los contratos financieros; pertinencia de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza para la resolución de instituciones financieras, y respeto de derechos sustantivos o créditos en un contexto de insolvencia transfronteriza

IX. Otros asuntos

110. Se insertó el siguiente texto nuevo en los párrafos 17 y 18 del documento A/CN.9/WG.V/WP.115:

- a) Al final de la nota 23, la frase “que regula las sociedades”; y
- b) Al final del párrafo 18, la oración: “No obstante, pueden aplicarse disposiciones diferentes a otras sociedades conforme a las normas de derecho civil”.

G. Nota de la Secretaría sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos enunciados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43º período de sesiones

(A/CN.9/WG.V/WP.112)

[Original: inglés]

Índice

Introducción	1
Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza	1
I. Finalidad y origen de la Ley Modelo	1
II. Finalidad de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación	1
III. La Ley Modelo como vehículo de armonización del derecho.	1
IV. Características principales de la Ley Modelo.	1
V. Observaciones a cada uno de los artículos	1
VI. Asistencia de la Secretaría de la CNUDMI	1

Introducción

1. En su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión tuvo ante sí una serie de propuestas sobre la labor futura en relación con el régimen de la insolvencia (A/CN.9/WG.V/WP.93 y Add.1 a 6 y A/CN.9/582/Add.6). Esas propuestas se habían examinado en el 38º período de sesiones del Grupo de Trabajo V (véase A/CN.9/691, párrs. 99 a 107) y se había hecho una recomendación a la Comisión sobre los posibles temas (A/CN.9/691, párr. 104). En otro documento (A/CN.9/709), presentado después de ese período de sesiones, se añadió material a la propuesta de Suiza que figuraba en el documento A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5.

2. Tras deliberar, la Comisión hizo suya la recomendación del Grupo de Trabajo V de que se empezaran a tratar dos temas relacionados con la insolvencia que tenían importancia en la actualidad y con respecto a los cuales un mayor grado de armonización de los enfoques de los distintos Estados serviría para introducir certeza y previsibilidad.

3. En la presente nota se examina el primero de esos dos temas, relativo a una propuesta de los Estados Unidos de América consignada en el párrafo 8 del documento A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.1, en la que se recomienda dar orientación sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza (la Ley Modelo) relacionados con el centro de los principales intereses y, posiblemente, elaborar una ley modelo o

disposiciones modelo sobre el régimen de la insolvencia en que se aborden determinadas cuestiones internacionales, como las relativas a la jurisdicción, el acceso a los tribunales extranjeros y el reconocimiento de los procedimientos extranjeros, de manera que no impida la preparación de una convención¹. El segundo tema, relacionado con las obligaciones de los directores de una empresa en el período previo a la insolvencia, se aborda en el documento A/CN.9/WG.V/WP.113.

4. Conforme a la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo en su 40º período de sesiones de que, como hipótesis de trabajo, cabría revisar y ampliar la Guía para la incorporación de la Ley Modelo al derecho interno (A/CN.9/738, párr. 13), en los documentos A/CN.9/WG.V/WP.95 y Add.1, A/CN.9/WG.V/WP.99, A/CN.9/WG.V/WP.103 y Add.1, A/CN.9/WG.V/WP.105 y A/CN.9/WG.V/WP.107, así como en los informes del Grupo de Trabajo sobre sus períodos de sesiones 39º, 40º, 41º y 42º (A/CN.9/715, 738, 742 y 763, respectivamente), figuran propuestas para la revisión de la Guía.

5. La presente nota está basada en esos documentos y contiene otros proyectos de revisión preparados a partir de las deliberaciones mantenidas y las decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo en su 42º período de sesiones. El lector podrá comprender mejor los cambios introducidos en la Guía consultando tanto la versión publicada de ese documento (disponible en: www.uncitral.org/uncitral/texts/insolvency.html) como el documento A/CN.9/WG.V/WP.107.

6. En la presente nota no se incluyen los párrafos de la versión publicada de la Guía que no se han revisado o que no contienen texto revisado; esto se señala mediante la indicación “[...]”. Cuando solo se proponen modificaciones editoriales de menor importancia no se consigna íntegramente el párrafo sino que se hace referencia al párrafo pertinente del documento que contiene esas modificaciones (es decir, el documento A/CN.9/WG.V/WP.107). Para facilitar la consulta, se mantienen los números de párrafo de la versión publicada de la Guía a fin de indicar cómo se ha reordenado el texto y los nuevos párrafos propuestos. Por lo tanto, la numeración de los párrafos en la presente nota no es necesariamente secuencial. En los casos en que se ha añadido un nuevo párrafo, este lleva el número del párrafo inmediatamente anterior seguido de una letra. Se han incluido todos los encabezamientos del texto publicado para indicar el contenido y facilitar la comparación con el texto publicado.

7. No se repiten las notas de pie de página de la versión publicada de la Guía que se mantienen sin cambios (si bien siguen figurando en el texto los caracteres que las indican); ahora bien, como la ubicación de algunas de las notas originales ha cambiado, se indica su lugar mediante una nota entre corchetes. Se ha incluido el texto de las notas nuevas y el de las modificadas. Se han omitido las secciones de la Guía tituladas “Examen en la Comisión o en el Grupo de Trabajo”, en las que se enumeran los documentos pertinentes, si bien se incluirán en la versión final -actualizadas para reflejar tanto las deliberaciones originales como las actuales- junto con el texto de cada artículo.

¹ Véase la propuesta conexas de la Unión Internacional de Abogados, relativa a la posibilidad de preparar una convención, a la que se hace referencia en A/CN.9/686, párrs. 127 a 130.

8. Tal vez el Grupo de Trabajo desee tomar nota de varias cuestiones pendientes surgidas en los debates mantenidos en su 42º período de sesiones:

a) La nota 22 al párrafo 123K se puso entre corchetes a solicitud del Grupo de Trabajo (A/CN.9/763, párr. 47);

b) Como el párrafo 123F se refiere actualmente a dos factores principales únicamente, no parecen apropiadas las palabras “considerados globalmente”, que podrían sustituirse por “considerados conjuntamente”;

c) El texto de los párrafos 128D y 128L es nuevo. El párrafo 128D se refiere al momento de determinar la existencia de establecimiento y fue elaborado por la Secretaría a solicitud del Grupo de Trabajo (A/CN.9/763, párr. 52). Material del anterior proyecto de párrafo 128L, relativo al abuso del proceso, figura ahora a continuación del párrafo 123J (A/CN.9/763, párr. 54).

9. Tal vez el Grupo de Trabajo desee también tomar nota de la conclusión a que llegó en su 40º período de sesiones (A/CN.9/738, párrs. 36 y 37) sobre la posibilidad de agregar a la Guía material relativo a los grupos de empresas, con respecto a la cual, si bien se expresaron algunas reservas en cuanto a su conveniencia, se convino en que en la Guía debería hacerse referencia a la tercera parte de la Guía Legislativa y a las soluciones adoptadas con respecto al trato de los grupos en situación de insolvencia, en particular en el contexto internacional. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar esa conclusión e indicar su opinión sobre si se debería o no agregar material y, en la afirmativa, qué material debería agregarse.

Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza

I. Finalidad y origen de la Ley Modelo

A. Finalidad de la Ley Modelo

1. La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza, aprobada en 1997, tiene por objeto ayudar a los Estados a dotar a su derecho de la insolvencia de una normativa moderna, equitativa y armonizada para abordar con mayor eficacia los casos de procedimientos transfronterizos en los que el deudor se encuentre en graves apuros financieros o sea insolvente. Esos casos incluyen aquellos en que el deudor tenga bienes en más de un Estado o en que algunos de los acreedores del deudor no sean del Estado en el que tiene lugar el procedimiento de insolvencia. En principio, se espera que el procedimiento pendiente en el centro de los principales intereses del deudor sea el determinante para hacer frente a la insolvencia del deudor, independientemente del número de Estados en los que este tenga bienes y acreedores, con sujeción a que se establezcan procedimientos de coordinación apropiados para ajustarse a las necesidades de cada Estado.

2. La Ley Modelo refleja las prácticas en materia de insolvencia transfronteriza que caracterizan a sistemas modernos y eficientes en esa esfera. Así pues, los

Estados que incorporen la Ley Modelo a su derecho interno (denominados “Estados promulgantes”) estarán introduciendo mejoras y adiciones útiles en sus respectivos regímenes internos de la insolvencia destinadas a resolver problemas que se plantean en casos de insolvencia transfronteriza. Al incorporar la Ley Modelo a su derecho interno, los Estados reconocen que para cumplir las normas internacionalmente reconocidas tal vez tengan que modificar algunas de sus leyes sobre insolvencia.

3. La Ley Modelo respeta las diferencias existentes en materia de derecho procesal entre los distintos Estados y no intenta lograr una unificación sustantiva del régimen de la insolvencia, sino que proporciona un marco de cooperación entre jurisdicciones, ofreciendo soluciones que sirven de ayuda de varias maneras que, aunque modestas, son significativas y facilitan cierto grado de armonización. Entre esas soluciones cabe citar las siguientes:

a) Después de “Estado promulgante” se ha insertado la siguiente nota: “El “Estado promulgante” es el Estado que ha promulgado legislación basada en la Ley Modelo. A menos que se disponga de otro modo, esa expresión se utiliza en la Guía para hacer referencia al Estado que reciba una solicitud en virtud de la Ley Modelo.”;

b) a f) [...];

g) Las palabras “en favor de” se han sustituido por las palabras “para prestar asistencia en”.

3A. Para los países ya habituados a tener que resolver numerosos casos de insolvencia transfronteriza y los que deseen prepararse como es debido para la eventualidad cada vez más probable de que esos casos proliferen, la Ley Modelo es un punto de referencia esencial para la elaboración de un marco efectivo de cooperación transfronteriza.

B. Origen de la Ley Modelo

13. [...]

18. Con respecto a modificaciones de menor importancia, véase A/CN.9/WG.V/WP.103, párr. 18².

19. [...]

C. Labor preparatoria y adopción

4. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) inició el proyecto en estrecha colaboración con INSOL International,

² A título informativo únicamente: los párrafos 18, 19, 31, 72, 74 y 75 de la Guía original se actualizaron en 2004 para tener en cuenta la entrada en vigor del Reglamento (CE) núm. 1346/2000 del Consejo de la Unión Europea sobre procedimientos de insolvencia, de 29 de mayo de 2000 (véase A/59/17, párr. 51) y están incluidos en la versión del texto publicada como anexo III de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia (publicación de las Naciones Unidas núm. de venta S.05.V.10).

que le proporcionó su asesoramiento especializado en todas las etapas de la labor preparatoria. Recibió asimismo asistencia, durante la formulación del texto de la Ley, del antiguo Comité J (Insolencia) de la Sección de Derecho Empresarial de la Asociación Internacional de Abogados.

5 a 7. Las notas se han actualizado; véase A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 5 a 7.

8. [...]

II. Finalidad de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación

9. La Comisión estimó que la Ley Modelo resultaría más eficaz si iba acompañada de información general y explicativa. Esa información iría destinada en primer lugar a las ramas de los poderes ejecutivo y legislativo de los gobiernos encargadas de revisar las leyes pertinentes, pero aportaría también ideas útiles a los encargados de interpretar y aplicar la Ley Modelo, por ejemplo los jueces³, y a otros usuarios del texto tales como profesionales y académicos. Esa información también podría ayudar a los Estados a determinar las disposiciones que, llegado el caso, deberían adaptarse para abordar la situación interna del Estado interesado.

10. La presente Guía, preparada por la Secretaría conforme a la solicitud formulada por la Comisión al final de su 30º período de sesiones, en 1997, está basada en las deliberaciones mantenidas y las decisiones adoptadas por la Comisión en ese 30º período de sesiones⁴, en el que se aprobó la Ley Modelo, así como en las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolencia, que se encargó de la labor preparatoria. La Guía se revisó, atendiendo a una solicitud de la CNUDMI, en su 43º período de sesiones (2010)⁵, con el fin de incluir nuevas orientaciones con respecto a la interpretación y aplicación de determinados aspectos de la Ley Modelo relativos al “centro de los principales intereses”. Las revisiones se basan en las deliberaciones que mantuvo el Grupo de Trabajo en sus períodos de sesiones 39º (2010), 40º (2011), 41º (2012), 42º (2012) y 43º (2013), así como en las que mantuvo la Comisión en su 46º período de sesiones (2013), y fueron adoptadas como Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo el ... de julio de 2013.

III. La Ley Modelo como vehículo de armonización del derecho

11. [...]

³ Por “juez” se entendería un magistrado u otra persona facultada para ejercer los poderes de un tribunal u otra autoridad competente en virtud de la legislación interna en materia de insolencia [por la que se incorpore la Ley Modelo].

⁴ [nota 8] *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/52/17)*, párr. 220.

⁵ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17)*, párr. 259.

A. Flexibilidad de la ley modelo

12. [...]

B. Integración de la Ley Modelo en el derecho interno existente

20. [...]

a), d) a f) [...];

b) Añádase la referencia “(artículo 20)” al final del párrafo;

c) [No se aplica en español.]

21. La flexibilidad de adaptación de la Ley Modelo al derecho interno del Estado promulgante debe ser utilizada con cautela para no arriesgar la necesaria uniformidad de su interpretación (véanse los párrs. 91 y 92) y el interés del Estado promulgante en adoptar prácticas internacionales modernas y generalmente aceptables en materia de insolvencia. Se aconseja, pues, limitar al mínimo todo desvío respecto del texto uniforme. Ello contribuirá a que la legislación nacional sea lo más transparente posible para los extranjeros que deban consultarla (véanse también los párrs. 11 y 12 *supra*). La uniformidad y la transparencia tienen la ventaja de facilitar la demostración por los Estados promulgantes del fundamento de su legislación nacional en materia de insolvencia transfronteriza y la obtención en otros Estados de colaboración en asuntos de insolvencia.

49. [...]

IV. Características principales de la Ley Modelo

49A. El texto de la Ley Modelo se centra en cuatro elementos fundamentales reconocidos, tras los estudios y consultas realizados a principios de los años 90, antes de su negociación, como ámbitos en los que tal vez se podría alcanzar un acuerdo internacional:

a) El acceso a los tribunales de un Estado para los representantes de procedimientos de insolvencia sustanciados en el extranjero y para los acreedores, y la autorización a los representantes de procedimientos de un Estado para solicitar asistencia en otro;

b) El reconocimiento de determinadas órdenes dictadas por tribunales extranjeros;

c) El otorgamiento de medidas para ayudar a sustanciar procedimientos extranjeros;

d) La cooperación entre los tribunales de los Estados en que estén ubicados los bienes del deudor y la coordinación de procedimientos paralelos.

A. Acceso

49B. Las disposiciones sobre el acceso abordan los aspectos de los procedimientos de insolvencia transfronteriza relacionados tanto con la actuación de un representante del Estado promulgante en el extranjero como con la de un representante extranjero en el Estado promulgante. En el primer caso, se autoriza a la persona u órgano que administra la reorganización o liquidación con arreglo a las leyes del Estado promulgante (denominado “representante de la insolvencia”)⁶ a actuar en un Estado extranjero (artículo 5) en representación de un procedimiento abierto en su Estado. En el segundo, un representante extranjero que desee actuar en el Estado promulgante tiene los siguientes derechos: derecho de acceso directo a los tribunales del Estado promulgante (artículo 9); derecho a solicitar la apertura de un procedimiento en el Estado promulgante con arreglo a las condiciones aplicables en dicho Estado (artículo 11), y derecho a solicitar el reconocimiento del procedimiento extranjero para el cual se le ha nombrado (artículo 15). Tras el reconocimiento, el representante extranjero está facultado para participar en todo procedimiento que se haya abierto en el Estado promulgante sobre asuntos de insolvencia con arreglo a la legislación de dicho Estado (artículo 12); para entablar una acción en el Estado promulgante a fin de anular o de otro modo dejar sin efecto todo acto perjudicial para los acreedores (artículo 23), y para intervenir en todo procedimiento local en el que el deudor sea parte (artículo 24).

49C. El hecho de que un representante extranjero tenga derecho a presentar una solicitud ante un tribunal del Estado promulgante no supone la sumisión de dicho representante extranjero, ni de los bienes o negocios del deudor en el extranjero, a la jurisdicción de los tribunales de ese Estado para efecto alguno que sea distinto de la solicitud (artículo 10).

49D. Una característica importante es que los acreedores extranjeros gozarán de los mismos derechos que los acreedores nacionales respecto de la apertura de un procedimiento en el Estado promulgante y de la participación en él (artículo 13).

37. [...]

B. Reconocimiento

37A. Uno de los objetivos fundamentales de la Ley Modelo es establecer procedimientos más sencillos para el reconocimiento de procedimientos extranjeros que reúnan las condiciones requeridas, lo que evitaría largos procesos de legalización o de otro tipo y aportaría certidumbre con respecto a la decisión de reconocer. El objetivo de la Ley Modelo no es permitir el reconocimiento de todos los procedimientos de insolvencia extranjeros. En el artículo 17 se dispone que, salvo lo dispuesto en el artículo 6, cuando se cumplan los requisitos del artículo 2 sobre las características del procedimiento extranjero (es decir, que el

⁶ Esta terminología, que refleja la del artículo 5 de la Ley Modelo, se utiliza para compatibilizar el texto con el de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia, en que se explica que el “representante de la insolvencia es “la persona o la entidad, incluso cuando su designación sea a título provisional, que haya sido facultada en un procedimiento de insolvencia para administrar la reorganización o la liquidación de la masa de la insolvencia”: Introducción, párr. 12 v).

procedimiento extranjero sea en realidad un procedimiento colectivo⁷ para los fines de la liquidación o la reorganización bajo el control o la supervisión del tribunal) y el representante extranjero, y se hayan aportado las pruebas que exige el artículo 15, el tribunal otorgará reconocimiento al procedimiento extranjero sin ningún otro requisito. El procedimiento de solicitud y reconocimiento se apoya en las presunciones que figuran en el artículo 16, que permiten al tribunal del Estado promulgante presuponer la autenticidad y validez de los certificados y documentos provenientes del Estado extranjero que exige el artículo 15.

37B. El artículo 6 permite que se deniegue el reconocimiento en los casos en que esta medida resulte “manifiestamente contraria al orden público” del Estado en que se procure obtener el reconocimiento. Tal vez sea esta una cuestión preliminar para tener en cuenta al examinar una solicitud de reconocimiento. No se intenta definir el concepto de orden público puesto que este varía de un Estado a otro. No obstante, la intención es que la excepción se interprete en sentido estricto y que el artículo 6 se utilice únicamente en circunstancias excepcionales y limitadas (véanse los párrs. 86 a 89). Las diferencias de los regímenes de insolvencia no justifican por sí mismas la conclusión de que la aplicación de las leyes de un Estado constituiría la violación del orden público de otro Estado.

37C. Un procedimiento extranjero debe reconocerse ya sea como procedimiento principal o no principal (artículo 17, párr. 2). Un procedimiento principal es el que se tramita en el Estado en que el deudor tenga el centro de sus principales intereses en la fecha de comienzo del procedimiento extranjero (véanse los párrs. ... con respecto al momento). En principio, se espera que el procedimiento principal sea el determinante para hacer frente a la insolvencia del deudor, independientemente del número de Estados en los que este tenga bienes y acreedores, con sujeción a que se establezcan procedimientos de coordinación apropiados para atender las necesidades de cada Estado. El concepto de centro de los principales intereses no se define en la Ley Modelo, pero se basa en la presunción de que es el domicilio social o la residencia habitual del deudor (artículo 16, párr. 3).

37D. El procedimiento no principal es el que se tramita donde el deudor tiene un establecimiento, concepto que se define como “todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes o servicios” (artículo 2, inciso f)). Los procedimientos basados en otros hechos, como la presencia de bienes, sin que haya centro de los principales intereses o establecimiento, no podrían ser reconocidos con arreglo a la Ley Modelo. Se examinan más detalladamente los procedimientos principales y los no principales en los párrafos [...] *infra*.

37E. Reconociendo que podría descubrirse posteriormente que en el momento de otorgar el reconocimiento no había motivos que lo justificaran, o que los motivos existentes hubieran cambiado o dejado de existir, la Ley Modelo permite la modificación o revocación del reconocimiento (artículo 17, párr. 4).

37F. El reconocimiento de los procedimientos extranjeros en virtud de la Ley Modelo tiene varios efectos. El más importante de ellos es que se permite otorgar medidas para prestar asistencia al procedimiento extranjero (artículos 20 y 21), pero además, como se ha indicado anteriormente, el representante extranjero tiene

⁷ Con respecto a lo que constituye un procedimiento colectivo, véanse los párrs. [...] *infra*.

derecho a participar en todos los procedimientos de insolvencia abiertos en el Estado extranjero que tengan que ver con el deudor (artículo 13), está legitimado para entablar acciones para evitar operaciones anteriores (artículo 23) y podrá intervenir en todo procedimiento en el que el deudor sea parte (artículo 24).

C. Medidas otorgables

37G. Un principio básico de la Ley Modelo es que deben otorgarse las medidas que se consideren necesarias para el desarrollo ordenado y equitativo del procedimiento de insolvencia transfronteriza extranjero, ya sean medidas provisionales o posteriores al reconocimiento. Por consiguiente, la Ley Modelo especifica qué medidas se pueden otorgar en cada uno de esos casos. Esto no supone necesariamente que se incorporen los efectos de la ley del foro extranjero al régimen interno de la insolvencia del Estado promulgante ni que se apliquen al procedimiento extranjero las medidas que serían otorgables con arreglo a la ley del foro del Estado promulgante. No obstante, como se señala más arriba, existe la posibilidad de alinear las medidas resultantes del reconocimiento de un procedimiento extranjero con las otorgables en un procedimiento comparable iniciado conforme al derecho interno del Estado promulgante (artículo 20).

37H. El tribunal podrá otorgar medidas provisionales desde la presentación de la solicitud de reconocimiento hasta que se resuelva esa solicitud (artículo 19); se pueden otorgar determinados tipos de medidas si el procedimiento se reconoce como principal (artículo 20); y se prevén medidas otorgables por el tribunal, a título discrecional, para procedimientos tanto principales como no principales, a partir del reconocimiento (artículo 21). En el caso de un procedimiento principal, esas medidas discrecionales se añadirían a las medidas otorgables tras el reconocimiento. Se podría prestar asistencia adicional en el marco de otras leyes del Estado promulgante (véase el artículo 7).

32. Se han suprimido las palabras “del representante” en la primera oración y la palabra “equitativa” en la tercera.

33. [...]

33A. En lo que respecta a las medidas provisionales y discrecionales, el tribunal podrá imponer condiciones y modificar o revocar dichas medidas a fin de proteger los intereses de los acreedores y otras personas interesadas afectadas por las medidas que se hubieran ordenado (artículo 22).

D. Cooperación y coordinación

Cooperación

33B. La Ley Modelo faculta expresamente a los tribunales para cooperar con sus homólogos extranjeros en las esferas que regula la Ley Modelo y comunicarse directamente con ellos. También autoriza la cooperación entre los tribunales y los representantes extranjeros y entre estos últimos. La cooperación no depende del reconocimiento y, por lo tanto, puede tener lugar en una etapa temprana y antes de que se formule la solicitud de reconocimiento. Dado que los artículos del capítulo IV se aplican a las cuestiones que se mencionan en el artículo 1, se puede

obtener cooperación con respecto no solo a las solicitudes de asistencia presentadas en el Estado promulgante, sino también a las solicitudes en relación con un procedimiento que se esté tramitando en el Estado promulgante con fines de prestación de asistencia en el extranjero (véase también el artículo 5). Además, la cooperación no se limita a los procedimientos extranjeros en el sentido del artículo 2, inciso a) que los habilitaría para el reconocimiento de conformidad con el artículo 17 (es decir, independientemente de que sean principales o no principales), por lo cual podrá obtenerse cooperación con respecto a procedimientos iniciados sobre la base de la presencia de bienes. La cuestión de la cooperación se examina detalladamente en los párrafos 173 a 183.

33C. Reconociendo que la idea de cooperación podría ser desconocida para muchos magistrados y representantes de la insolvencia, en el artículo 27 de la Ley Modelo se enumeran posibles medios de cooperación. Estos se examinan más a fondo y se amplían en la Guía de Prácticas de la CNUDMI sobre Cooperación en la Insolvencia Transfronteriza⁸, que también recoge prácticas y experiencias relacionadas con el uso y la negociación de acuerdos de insolvencia transfronteriza.

Coordinación de procedimientos paralelos

33D. Varias disposiciones de la Ley Modelo se refieren a la coordinación de procedimientos paralelos y tienen por objeto fomentar la adopción de las decisiones óptimas para el logro de los objetivos de ambos procedimientos.

33E. El reconocimiento de un procedimiento extranjero principal no impide que se inicie un procedimiento interno en el Estado promulgante (artículo 28), y la apertura de un procedimiento interno en ese Estado no significa el fin del reconocimiento ya otorgado a procedimientos extranjeros ni impide que se reconozcan nuevos procedimientos extranjeros.

33F. El artículo 29 trata de los ajustes de las medidas otorgadas en el caso de que haya procedimientos paralelos. El principio básico es que las medidas otorgadas para un procedimiento extranjero reconocido deberán ser compatibles con las medidas otorgadas en el procedimiento interno, independientemente de que este se haya iniciado antes o después del reconocimiento del procedimiento extranjero. Por ejemplo, cuando el procedimiento interno esté en curso en el momento de presentarse la solicitud de reconocimiento del procedimiento extranjero, toda medida otorgada al procedimiento extranjero deberá ser compatible con el procedimiento interno. De reconocerse el procedimiento extranjero como procedimiento principal, no se aplicarán las medidas otorgables automáticamente tras el reconocimiento previstas en el artículo 20.

33G. Los artículos 31 y 32 establecen otros medios para facilitar la coordinación. El artículo 31 establece una presunción en el sentido de que el reconocimiento de un procedimiento extranjero constituirá una prueba de que el deudor es insolvente cuando se requiera la existencia de insolvencia para la apertura de un procedimiento con arreglo al derecho interno. El artículo 32 establece una regla de pago cuya finalidad es evitar situaciones en las que un acreedor pueda reclamar y cobrar su deuda en múltiples procedimientos de insolvencia seguidos en distintas

⁸ Puede consultarse el texto de la Guía de Prácticas en la siguiente dirección:
www.uncitral.org/uncitral/spanish/uncitral_texts.html.

jurisdicciones y, de esta forma, pueda obtener un trato más favorable con respecto a los demás acreedores.

V. Observaciones a cada uno de los artículos

Preámbulo

54. Se han sustituido las últimas palabras de la segunda oración por las palabras “y facilitar su interpretación.”

55. [...]

Utilización del término “insolvencia”

51. Reconociendo que cada jurisdicción puede tener una idea distinta de lo que comprende la expresión “procedimiento de insolvencia”, la Ley Modelo no define el concepto de “insolvencia”⁹. No obstante, la palabra se utiliza en la Ley Modelo con referencia a diversos tipos de procedimientos colectivos abiertos contra deudores que se encuentren en graves apuros financieros o sean insolventes. La razón es que la Ley Modelo se ocupa de procedimientos contra diversos tipos de deudores, entre ellos procedimientos destinados a la reorganización del patrimonio del deudor o a la liquidación de sus bienes. No se consideran procedimientos de insolvencia en el marco de la Ley Modelo los procedimientos judiciales o administrativos para concluir la actividad de una entidad solvente con fines de su disolución ni otros procedimientos extranjeros a los que no sea aplicable el inciso a) del artículo 2.

51A. Los tipos de deudores a que se refiere la Ley Modelo son por lo general los que abarca la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia de la CNUDMI y, por lo tanto, serían quienes podrían solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia de conformidad con las recomendaciones 15 y 16 de la Guía Legislativa¹⁰, al tratarse de deudores que no están o no estarán, en general, en condiciones de pagar sus deudas a su vencimiento o cuyas deudas exceden del valor de sus bienes.

52 a 53. [...]

⁹ La Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia de la CNUDMI define la insolvencia como el “estado de un deudor que no puede atender al pago general de sus deudas a su vencimiento o estado financiero de una empresa cuyo pasivo excede del valor de su activo”, y el procedimiento de insolvencia como un “procedimiento colectivo sujeto a supervisión judicial, que se sustancia con miras a la reorganización o liquidación de una empresa insolvente”.

¹⁰ Las recomendaciones 15 y 16 establecen lo siguiente:

15. El régimen de la insolvencia debería especificar que un procedimiento de insolvencia puede abrirse a instancia del deudor, si este puede demostrar que:

- a) No está o no estará, en general, en condiciones de pagar sus deudas a su vencimiento; o
- b) Sus deudas exceden del valor de sus bienes.

16. El régimen de la insolvencia debería especificar que el procedimiento de insolvencia puede abrirse a instancia de un acreedor siempre que pueda demostrarse que:

- a) El deudor no está, en general, en condiciones de pagar sus deudas a su vencimiento; o
- b) Las deudas del deudor exceden del valor de sus bienes.

“Estado”

56. Al final del párrafo se ha añadido la siguiente oración: “El texto que finalmente se promulgue podrá utilizar la expresión de derecho interno que sea habitual a ese respecto”.

Capítulo I. Disposiciones generales*Artículo 1. Ámbito de aplicación**Párrafo 1*

57. [...]

58. [Incorporado al párrafo 56]

59. El término “asistencia” que se utiliza en los incisos a) y b) del párrafo 1 engloba diversos supuestos, examinados en la Ley Modelo, en los que un tribunal o un representante de la insolvencia en un Estado podrá solicitar de un tribunal o un representante de la insolvencia en otro Estado la adopción de una medida prevista por la Ley Modelo. Algunas de esas medidas están expresamente previstas en el texto de la Ley Modelo (por ejemplo, en el artículo 19, incisos 1 a) y b); en el artículo 21, incisos 1 a) a f) y párrafo 2; y en el artículo 27, incisos a) a e)), mientras que otras están previstas en términos más genéricos (como en el artículo 21, inciso 1 g)).

Párrafo 2 (Regímenes especiales de la insolvencia)

60 a 64. [...]

65. En las palabras que figuran entre paréntesis se ha sustituido “la norma interna” por “una ley”.

Personas naturales o no comerciantes

66. [...]

*Artículo 2. Definiciones**Incisos a) a d)*

67. [...]

68. [No se aplica en español.]

68A. Los procedimientos y los representantes extranjeros que no posean esos atributos no podrían ser reconocidos con arreglo a la Ley Modelo.

Inciso a) - Procedimiento extranjero

71. Al final del párrafo se han añadido las palabras “o son insolventes”.

72. Este párrafo se ha suprimido; la cuestión se examina con detalle en los párrafos 31 y siguientes.

23. Entre los atributos que un procedimiento extranjero deberá poseer para caer dentro del ámbito de aplicación de la Ley Modelo figuran los siguientes: un fundamento en el derecho interno de la insolvencia del Estado de origen; una

representación colectiva de los acreedores; el control o la supervisión de los bienes o negocios del deudor por un tribunal u otro órgano oficial; y la reorganización o liquidación del negocio del deudor como finalidad del procedimiento (inciso a) del artículo 2). Se determinaría si un procedimiento extranjero posee esos elementos al examinar la solicitud de reconocimiento.

23A. Como se señala en el inciso e) del preámbulo, la Ley Modelo se centra en los deudores que se encuentran en graves apuros financieros o que son insolventes y en las leyes que previenen o hacen frente a los apuros financieros de esos deudores. Como se señala más arriba (párr. 51A), se trata de deudores que en general cumplirían los criterios de apertura examinados en la Guía Legislativa, al ser deudores que no están o no estarán, en general, en condiciones de pagar sus deudas a su vencimiento o cuyas deudas exceden del valor de sus bienes (recomendaciones 15 y 16).

23A *bis*. En los párrafos siguientes se examinan diversas características exigidas a un “procedimiento extranjero” con arreglo al artículo 2. Si bien se examinan por separado, esas características son acumulativas, y el inciso a) del artículo 2 debería considerarse en su conjunto.

i) *El procedimiento colectivo*

23B. Para que puedan otorgarse medidas en un procedimiento conforme a la Ley Modelo, deberá tratarse de un procedimiento colectivo, ya que la Ley Modelo tiene por objeto servir de instrumento para llegar a una solución coordinada y global para todas las partes interesadas en el procedimiento de insolvencia. La Ley Modelo no debe entenderse como un mero mecanismo de cobro para un determinado acreedor o grupo de acreedores que puedan haber entablado un procedimiento en otro Estado con el fin de cobrar sus créditos. Tampoco se pretende que sea un instrumento encaminado a acumular bienes en un procedimiento de liquidación¹¹ o de rehabilitación que no prevea también disposiciones para atender las reclamaciones de los acreedores. La Ley Modelo puede ser un instrumento apropiado para cierta clase de acciones que tengan fines de reglamentación, por ejemplo, la administración judicial de entidades sujetas a reglamentación pública como las compañías de seguros o las empresas de corretaje, siempre y cuando el procedimiento sea colectivo en el sentido en que se emplea ese término en la Ley Modelo. Para que un procedimiento sea colectivo, también debe reunir los demás elementos de la definición, entre ellos que tenga como fin la liquidación o la reorganización (véanse los párrs. 24F y G *infra*).

23C. Al evaluar si un determinado procedimiento es colectivo a efectos de la Ley Modelo, una de las consideraciones fundamentales es determinar si en el procedimiento se tienen en cuenta prácticamente todos los bienes y las deudas del deudor, sin perjuicio de las prioridades y excepciones legislativas del país, ni de la exclusión de determinados derechos de los acreedores garantizados en su ordenamiento jurídico. No se puede considerar que un procedimiento no es colectivo únicamente por el hecho de que no afecte a los derechos de una clase de acreedores. Un ejemplo es el procedimiento de insolvencia en que se excluyen los bienes gravados de la masa de la insolvencia, de tal manera que no les afecte la

¹¹ La “liquidación” es un procedimiento por el cual se pone fin a la existencia de una empresa y de sus negocios.

apertura del procedimiento y se permita a los acreedores garantizados hacer valer sus derechos al margen del régimen de la insolvencia (véase la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia, segunda parte, cap. II, párrs. 7 a 9). Otra manera de tratar a los acreedores en un procedimiento colectivo a efectos del artículo 2 es otorgar a los que se vean perjudicados por el procedimiento el derecho (aunque no necesariamente la obligación) de presentar sus créditos con miras a que se adopte una determinación, y recibir una parte equitativa en la distribución que se haga, o a la satisfacción de esos créditos, de participar en el procedimiento y de que este se les notifique a fin de facilitar su participación. La Guía Legislativa se extiende detalladamente sobre los derechos de los acreedores, incluido el de participar en el procedimiento (segunda parte, cap. III, párrs. 75 a 112).

24. Conforme a los criterios de la definición de un procedimiento extranjero, podría otorgarse el reconocimiento a diversos tipos de procedimientos colectivos: obligatorios o voluntarios; relativos a personas jurídicas o a personas naturales; de liquidación o de reorganización. La definición incluiría también los procedimientos en que el deudor conserva cierto control sobre sus bienes, aun cuando haya de actuar bajo la supervisión del tribunal (por ejemplo, suspensión de pagos (“deudor en posesión”)).

24A. En la Ley Modelo se reconoce que, para ciertos fines, se pueden iniciar procedimientos de insolvencia en caso de darse determinadas circunstancias prescritas por la ley que no significan necesariamente que el deudor sea de hecho insolvente. En el párrafo 194 *infra* se señala que entre esas circunstancias puede darse la suspensión de pagos del deudor o ciertos actos del deudor, como una decisión que concierna a la empresa, la dispersión de sus bienes o el abandono de su establecimiento. En el párrafo 195 *infra* se indica que en los casos en que la insolvencia sea una condición para iniciar un procedimiento de insolvencia el artículo 31 establece, al reconocerse un procedimiento extranjero principal, una presunción *juris tantum* de insolvencia del deudor para los fines de iniciar un procedimiento de insolvencia con arreglo al derecho interno.

ii) *El procedimiento seguido con arreglo a una norma relativa a la insolvencia*

24B. Esta formulación se utiliza en la Ley Modelo para reconocer el hecho de que la liquidación y la reorganización pueden realizarse en virtud de una legislación que no esté comprendida en el régimen de la insolvencia (por ejemplo, el derecho de sociedades), pero que no obstante regule o aborde cuestiones relacionadas con la insolvencia o situaciones de graves apuros financieros. Se trataba de hallar una descripción lo suficientemente amplia como para abarcar una gama de normas de insolvencia independientemente del tipo de instrumento legislativo en el que estuvieran incluidas¹² y de si este se refería o no exclusivamente a la insolvencia. Un procedimiento sencillo para una entidad jurídica solvente que no busque reestructurar sus asuntos financieros sino disolverse como entidad jurídica no es probable que se rija por una ley relativa a la insolvencia o a situaciones de graves apuros financieros.

¹² A/CN.9/422, párr. 49.

iii) Control o supervisión de un tribunal extranjero

24C. En la Ley Modelo no se definen el grado de control o supervisión necesario para cumplir este aspecto de la definición ni el momento en que se debe proceder a ese control o esa supervisión. Aunque la intención es que el control o la supervisión que exige el inciso a) sea de índole oficial, puede ser más potencial que real. Como se señala en el párrafo 24, los procedimientos en que el deudor conserva cierto control sobre sus bienes, aun cuando haya de actuar bajo la supervisión del tribunal, como en el caso del deudor en posesión, cumplirían ese requisito. El control o la supervisión puede ejercerlo no solo el tribunal directamente sino también un representante de la insolvencia en el caso, por ejemplo, de que dicho representante esté sujeto al control o la supervisión del tribunal. La mera supervisión de un representante de la insolvencia por una autoridad expedidora de licencias no bastaría.

24D. No se deberían excluir los procedimientos agilizados a que se hace referencia en la Guía Legislativa (véanse la segunda parte, cap. IV, párrs. 76 a 94, y las recomendaciones 160 a 168). Son procedimientos en los que el tribunal ejerce el control o la supervisión en una fase avanzada del procedimiento de insolvencia. Tampoco se deben excluir los procedimientos en que el tribunal ha ejercido el control o la supervisión pero deja de estar obligado a ello una vez que se presenta la solicitud de reconocimiento. Un ejemplo de esto último podrían ser los casos en que se haya aprobado un plan de reorganización y, aunque el tribunal no tenga una función continua con respecto a su aplicación, los procedimientos sigan abiertos o pendientes y el tribunal mantenga la jurisdicción hasta que concluya la aplicación.

24E. En el inciso a) del artículo 2 se deja claro que tanto los bienes como los negocios del deudor deben estar sujetos a control o supervisión judicial; no basta con que solo una cosa o la otra quede abarcada por el procedimiento extranjero.

iv) A los efectos de reorganización o liquidación

24F. Algunos tipos de procedimiento que tal vez satisfagan algunos elementos de la definición de procedimiento extranjero que figura en el inciso a) del artículo 2 pueden no obstante no ser reconocibles por el hecho de no tener por objeto la reorganización o liquidación. Estos procedimientos pueden adoptar diversas formas, incluso puede tratarse de procedimientos concebidos para impedir la dispersión y el desperdicio de los bienes, y no para liquidar o reorganizar la masa de la insolvencia; de procedimientos para impedir que se causen perjuicios a los inversionistas, y no a la totalidad de los acreedores (en cuyo caso es probable que no se trate de un procedimiento colectivo); o de procedimientos en los que los poderes conferidos y los deberes impuestos al representante extranjero sean más limitados que los habituales en los casos de liquidación o reorganización, por ejemplo el poder que solo permite preservar los bienes.

24G. Entre los tipos de procedimiento que podrían no reconocerse figuran las medidas o arreglos de ajuste financiero, de naturaleza puramente contractual, concertados entre el deudor y algunos de sus acreedores en lo que respecta a determinada deuda cuando las negociaciones no conducen a la apertura de un

procedimiento de insolvencia de conformidad con la ley de la insolvencia¹³. Esas medidas no cumplirían generalmente el requisito de ser de carácter colectivo ni el relativo al control o la supervisión judicial (véanse los párrs. 24C a E). Dado que podrían ser medidas muy diversas, no se prestarían fácilmente a ser objeto de una regla general sobre el reconocimiento¹⁴. También podrían quedar excluidos otros procedimientos que no requieran supervisión o control judicial.

El procedimiento de índole provisional

69. [...]

70. Al final de la primera oración se ha añadido la referencia “(véanse los párrs. 133 y 134 *infra*”); la segunda oración se ha trasladado a las observaciones sobre el artículo 18.

Inciso b) - El procedimiento extranjero principal

31. Un procedimiento extranjero se tendrá por “principal” si ese procedimiento se ha abierto en el Estado “donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses”. Esta formulación refleja la del artículo 3 del Reglamento (CE) (basada en la formulación adoptada previamente en el Convenio de la Unión Europea relativo a los procedimientos de insolvencia (el Convenio Europeo)), contribuyendo así al consenso que se va formando sobre la noción de procedimiento “principal”. La determinación de si un procedimiento extranjero es o no “principal” puede afectar a la naturaleza de las medidas que sean otorgadas al representante extranjero con arreglo a los artículos 20 y 21 y a la coordinación del procedimiento extranjero con los procedimientos que puedan haberse iniciado en el Estado promulgante con arreglo al capítulo IV y con otros procedimientos paralelos conforme al capítulo V.

31A. La Ley Modelo no define el concepto de “centro de los principales intereses”. No obstante, un informe explicativo (el informe Virgós-Schmit)¹⁵, preparado en relación con el Convenio de la Unión Europea, ofrecía una orientación sobre el concepto de “procedimiento de insolvencia principal” y, a pesar de que el Convenio finalmente no entrará en vigor, en general se acepta que dicho informe es una ayuda para la interpretación de la expresión “centro de los principales intereses” que se utiliza en el Reglamento (CE). Dado que la formulación “centro de los principales intereses” que aparece en el Reglamento (CE) se corresponde con la que figura en la Ley Modelo, si bien con fines distintos (véase el párr. 123A), la jurisprudencia de interpretación del Reglamento (CE) también puede resultar pertinente para la interpretación de la Ley Modelo.

31B. Los párrafos introductorios 12) y 13) del Reglamento (CE) establecen lo siguiente:

¹³ Por supuesto, esos arreglos contractuales seguirían siendo ejecutables al margen de la Ley Modelo sin necesidad de reconocimiento; nada de lo dispuesto en la Ley Modelo ni en la Guía para su incorporación al derecho interno tiene por objeto restringir la posibilidad de ejecutarlos.

¹⁴ A/CN.9/419, párrs. 19 y 29.

¹⁵ M. Virgós y E. Schmit, Report on the Convention on Insolvency Proceedings, Bruselas, 3 de mayo de 1996. El informe se publicó en julio de 1996 y puede consultarse en inglés en la siguiente dirección: <http://aei.pitt.edu/952>.

“12) El presente Reglamento permite que los procedimientos principales de insolvencia se incoen en el Estado miembro en que el deudor tenga su centro de intereses principales. Dichos procedimientos tienen alcance universal y su objetivo es abarcar todos los bienes del deudor. Con objeto de proteger la diversidad de intereses, el presente Reglamento permite que se incoen procedimientos secundarios¹⁶ paralelamente al procedimiento principal; podrán incoarse procedimientos secundarios en el Estado miembro en que el deudor tenga un establecimiento. Los efectos de los procedimientos secundarios están limitados a los bienes situados en dicho Estado; unas disposiciones imperativas de coordinación con el procedimiento principal satisfacen la necesidad de unidad dentro de la Comunidad.

13) El ‘centro de los principales intereses’ debería corresponder al lugar donde el deudor lleve a cabo de manera habitual la administración de sus intereses y que, por consiguiente, pueda ser averiguado por terceros.”

31C. En el Informe Virgós-Schmit se explica el concepto de “procedimiento de insolvencia principal” del siguiente modo:

“73. Procedimiento de insolvencia principal

El párrafo 1 del artículo 3 permite abrir un procedimiento de insolvencia principal de alcance universal en el Estado contratante en que el deudor tenga el centro de sus principales intereses. El procedimiento de insolvencia principal tiene un ámbito universal. Su finalidad es abarcar todos los bienes del deudor en todo el mundo y afectar a todos los acreedores con independencia del lugar donde se encuentren.

En el ámbito territorial del Convenio solo podrá abrirse un procedimiento principal.

...

75. Se ha de interpretar que el concepto de ‘centro de los principales intereses’ designa el lugar desde donde el deudor administra sus intereses de forma ordinaria, que por lo tanto puede ser averiguado por terceros.

No es difícil explicar el motivo de esta norma. La insolvencia es un riesgo previsible. Por tanto, es importante que la jurisdicción se establezca a escala internacional en un lugar conocido por los posibles acreedores del deudor (como veremos, ello supone que se aplique el régimen de la insolvencia del correspondiente Estado contratante). De tal modo, podrán calcularse los riesgos jurídicos que se asumen en caso de insolvencia.

El propósito de utilizar el término ‘intereses’ es abarcar no solo las actividades comerciales, industriales o profesionales sino también las actividades económicas en general, de forma que se incluyan las actividades de personas físicas (por ejemplo, consumidores). El término ‘principales’ establece el criterio que ha de utilizarse para dirimir los casos en que los intereses representen actividades de distinto tipo y gestionadas desde distintos centros.

¹⁶ El Reglamento (CE) hace referencia a “procedimientos secundarios”, mientras que la Ley Modelo utiliza la expresión “procedimientos no principales”.

En principio, el centro de los principales intereses de un profesional será el lugar donde tenga su domicilio profesional, y el de las personas físicas en general el lugar de su residencia habitual.

En lo que respecta a las empresas y las personas jurídicas, el Convenio presume, salvo prueba en contrario, que el centro de los principales intereses del deudor es su domicilio social. Este lugar coincide normalmente con el lugar donde el deudor tiene su oficina principal.”

En las observaciones al artículo 16 se examina más a fondo el concepto de centro de los principales intereses.

Inciso c) - El procedimiento extranjero no principal

73. Al final de la primera oración se ha añadido una referencia a los párrafos 75 y 75A.

Inciso d) - Representante extranjero

73A. En el inciso d) se reconoce que el representante extranjero puede ser una persona autorizada en el procedimiento extranjero a administrar ese procedimiento, lo que abarca tratar de obtener el reconocimiento del procedimiento, el otorgamiento de medidas y cooperación en otro país, o simplemente una persona expresamente autorizada a representar el procedimiento. En la Ley Modelo no se especifica que el representante extranjero deba ser autorizado por el tribunal (con arreglo al inciso e) del artículo 2) y la definición es, pues, lo suficientemente amplia para abarcar los nombramientos que pueda hacer un organismo especial que no sea un tribunal. También están comprendidos los nombramientos hechos con carácter provisional (véanse los párrs. 69 y 70 *supra*). A efectos de la Ley Modelo, es suficiente el hecho de que en el procedimiento extranjero se haya nombrado al representante extranjero para actuar en una u otra de esas calidades, o en ambas; en el artículo 15 se exige una copia certificada de la decisión por la que se nombra al representante, un certificado en el que conste el nombramiento u otra prueba de ese nombramiento que sea aceptable para el tribunal ante el que se recurra. La definición que figura en el inciso d) es suficientemente amplia para abarcar a los deudores que sigan en posesión tras la apertura del procedimiento de insolvencia.

Inciso e)

74. Al final del párrafo, después de las palabras “inciso d) del artículo 2 del Reglamento (CE)”, se han añadido las palabras “así como en la Guía Legislativa (Introducción, párr. 12 i)), y la Guía de Prácticas de la CNUDMI (Introducción, párrs. 7 y 8)”.

Inciso f)

75. La definición del término “establecimiento” está inspirada en el inciso h) del artículo 2 del Reglamento de la Unión Europea. El término se utiliza en la Ley Modelo en la definición de “procedimiento extranjero no principal” (inciso c) del artículo 2) y en el contexto del párrafo 2 del artículo 17, con arreglo al cual, para que se reconozca un procedimiento extranjero no principal, es preciso que el deudor tenga un establecimiento en el territorio del Estado extranjero (véase también el párr. 73 *supra*).

75A. El Informe Virgós-Schmit sobre ese Convenio aporta nuevas explicaciones del término “establecimiento”:

“Por lugar de operaciones se entiende aquel en el que se ejerce una actividad económica en el mercado (es decir, una actividad hacia el exterior), sea esta comercial, industrial o profesional.

La importancia atribuida a la necesidad de que haya una actividad económica en la que se utilicen recursos humanos muestra la necesidad de que haya también un grado mínimo de organización. Un lugar de operaciones puramente ocasional no se puede considerar establecimiento. Se precisa una cierta estabilidad. La fórmula negativa (de forma no transitoria) pretende evitar el establecimiento de un requisito de tiempo mínimo. El factor decisivo es cómo se presenta exteriormente la actividad, y no la intención del deudor.¹⁷”

75B. Dado que “establecimiento” es un término definido, la averiguación que ha de hacer el tribunal de si el deudor cuenta con un establecimiento es de carácter puramente fáctico. A diferencia de lo que ocurre con un “procedimiento extranjero principal”, no hay presunción en lo que respecta a la determinación del establecimiento. Sí que plantea una cuestión de derecho, sin embargo, establecer si la expresión “de forma no transitoria” hace referencia a la duración de la actividad económica pertinente o la hace a la ubicación concreta en que se desarrolla la actividad. La apertura de un procedimiento de insolvencia, la existencia de deudas y la mera presencia de bienes aislados, de cuentas bancarias o de bienes inmuebles, no significaría, en principio, que se cumpliera con la definición de establecimiento.

Artículo 3. Obligaciones internacionales del Estado

76 y 77. [...]

78. [No se aplica en español.]

Artículo 4. [Tribunal o autoridad competente]¹⁸

79 a 83. [...]

Artículo 5. Autorización dada a [indíquese la denominación de la persona o del órgano que se encargue de administrar la reorganización o liquidación con arreglo al derecho interno de este Estado] *para actuar en un Estado extranjero.*

84. Se ha modificado la última frase de la siguiente manera: “Todo Estado promulgante en el que los representantes de la insolvencia estén ya facultados para actuar como representantes extranjeros podrá decidir omitir el artículo 5, aun cuando su mantenimiento constituiría una clara prueba legal de esas facultades y prestaría asistencia a los tribunales extranjeros y otros usuarios de la ley.”

¹⁷ Informe Virgós-Schmit, párr. 7.1.

¹⁸ [Nota I] Aquellos Estados en los que algunas de las funciones relacionadas con el procedimiento de insolvencia sean habitualmente conferidas a determinados mandatarios judiciales u órganos públicos podrán, si así lo desean, insertar en el artículo 4, o en algún otro lugar del capítulo I, la disposición siguiente:
Nada de lo dispuesto en la presente Ley afectará a las disposiciones de este Estado relativas a los poderes de que goza [indíquese la denominación de la persona u órgano habitualmente designado].

85. [...]

Artículo 6. Excepción de orden público

86 a 89. [...]

Artículo 7. Asistencia adicional en virtud de alguna otra norma

90. [...]

Artículo 8. Interpretación

91. La segunda oración se ha modificado de la siguiente manera: “Más recientemente, se ha reconocido la conveniencia de incluir una disposición de esa índole también en textos de derecho uniforme no convencional como el de una ley modelo, en razón del interés que tendrá el Estado promulgante en que se dé a su régimen una interpretación armónica.”

92. [...]

Capítulo II. Acceso de los representantes y acreedores extranjeros a los tribunales del Estado

Artículo 9. Derecho de acceso directo

93. Se ha añadido la siguiente oración introductoria: “Un objetivo importante de la Ley Modelo es dar a los representantes extranjeros acceso directo y rápido a los tribunales del Estado promulgante.”

Artículo 10. Jurisdicción limitada

94 y 95. [...]

96. [No se aplica en español.]

Artículo 11. Solicitud del representante extranjero de que se abra un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia]

97. [...]

98. Se ha modificado la primera oración de la siguiente manera: “El artículo 11 está formulado en términos que garantizan que el representante extranjero (de un procedimiento extranjero principal o no principal) goce de legitimidad¹⁹ para solicitar el comienzo de un procedimiento de insolvencia” y se ha añadido la nota.

99. [...]

Artículo 12. Participación de un representante extranjero en un procedimiento abierto con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia]

100. Este párrafo se ha alineado con el párrafo 98 y la nota 26.

101. Se ha modificado el final del párrafo de la siguiente manera: “la suerte de cualquiera de ellas”.

¹⁹ Llamada también “legitimación procesal”, “legitimación activa” o “legitimación”.

102. Al final del párrafo se han añadido las palabras “(véanse los párrs. 169 y 172 *infra*)”.

Artículo 13. Acceso de los acreedores extranjeros a un procedimiento abierto con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia]

103 a 105. [...]

Artículo 14. Notificación a los acreedores en el extranjero con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia]

106 a 111. [...]

Capítulo III. Reconocimiento de un procedimiento extranjero y medidas otorgables

Artículo 15. Solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero

112. Al principio del párrafo se han insertado las dos oraciones siguientes: “La Ley Modelo evita la necesidad de tener que recurrir a procedimientos engorrosos y lentos como la carta o comisión rogatoria, o a otras vías diplomáticas o consulares, que sin ella tal vez fueran necesarios. Ello facilita la adopción de un enfoque cooperativo y coordinado de la insolvencia transfronteriza y agiliza la adopción de medidas.”

113 a 118. [...]

119. El párrafo 4 autoriza, pero no obliga, al tribunal a exigir la traducción de algunos o todos los documentos que se presenten en apoyo de la solicitud de reconocimiento. De ser compatible con la práctica del foro, esa discrecionalidad puede facilitar la adopción de una decisión acerca de la solicitud a la mayor brevedad posible, conforme a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 17, siempre y cuando el tribunal esté en condiciones de examinar la solicitud sin disponer de la traducción de los documentos.

Notificación

120. Existen diferentes soluciones sobre si el tribunal debe dar aviso de una solicitud de reconocimiento. En algunos ordenamientos, se diría que ciertos principios fundamentales de legalidad del proceso, consagrados incluso en la constitución, no permiten adoptar una decisión tan importante como el reconocimiento de un procedimiento de insolvencia extranjero sin haber oído a las partes interesadas. En cambio, en otros Estados se considera que una solicitud de reconocimiento de un procedimiento de insolvencia extranjero ha de tramitarse rápidamente (ya que se presenta a menudo en situación de peligro inmediato de dispersión u ocultación de los bienes) y que, en consecuencia, no se requiere aviso previo de la decisión por la que el tribunal reconozca el procedimiento. En esas circunstancias, imponer ese requisito podría ocasionar una demora indebida y sería incompatible con el párrafo 3 del artículo 17, que dispone que una solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero deberá ser despachada a la mayor brevedad posible.

121. [...]

*Artículo 16. Presunciones relativas al reconocimiento**Párrafo 1*

122. El artículo 16 establece presunciones que permiten y fomentan que se actúe con rapidez en los casos en que podría ser fundamental. Esas presunciones permiten al tribunal agilizar la práctica de la prueba. Al mismo tiempo, no impiden que, con arreglo a la ley procesal interna, se pidan o tomen en consideración otras pruebas cuando se cuestione la conclusión dimanada de las presunciones.

122A. El párrafo 1 del artículo 16 establece una presunción con respecto a las definiciones de “procedimiento extranjero” y “representante extranjero” que figuran en el artículo 2. Si en la resolución por la que se declara abierto el procedimiento extranjero y se nombra al representante extranjero se indica que el procedimiento extranjero es un procedimiento en el sentido del inciso a) del artículo 2 y que el representante extranjero es una persona o un órgano en el sentido del inciso d) del artículo 2, el tribunal ante el que se recurra podrá presumir que ello es así. En la práctica, varios tribunales en esa situación se han basado en esa presunción en diversos casos cuando el tribunal que abrió el procedimiento había incluido esa información en la orden judicial²⁰.

122B. La inclusión de información relativa a la índole del procedimiento extranjero y el representante extranjero, definidos en el artículo 2, en las órdenes del tribunal que abrió el procedimiento extranjero puede facilitar la tarea del reconocimiento en los casos pertinentes. Esas órdenes o decisiones no son vinculantes para el tribunal del Estado promulgante al que se recurra, que debe cerciorarse por sí mismo de que se satisfacen los requisitos del artículo 2 (la cuestión se examina más a fondo en los párrs. 124B y C *infra*).

Párrafo 2

123. [...]

Párrafo 3

123A. Aunque la presunción enunciada en el párrafo 3 del artículo 16 se corresponde con la presunción del Reglamento del Consejo de la Unión Europea (Reglamento CE), tiene un propósito distinto. En la Ley Modelo, la presunción está concebida para facilitar el reconocimiento del procedimiento de insolvencia extranjero y prestar asistencia a ese procedimiento. En el Reglamento CE la presunción guarda relación con el lugar adecuado para abrir el procedimiento de insolvencia, estableciendo así el derecho aplicable, y el reconocimiento automático del procedimiento por otros Estados miembros de la Unión Europea. En virtud del Reglamento CE, el tribunal que recibe una solicitud para abrir un procedimiento de insolvencia toma la decisión sobre el centro de los principales intereses al examinar la solicitud. En el marco de la Ley Modelo, la solicitud de reconocimiento de un procedimiento extranjero puede presentarse en cualquier momento después de la apertura del procedimiento; en algunos casos se ha realizado varios años después. Así pues, el tribunal que analiza una solicitud de reconocimiento en virtud de la Ley Modelo debe determinar si el procedimiento extranjero respecto del que se solicita el reconocimiento tiene lugar en un foro que era el centro de los principales

²⁰ Pueden verse ejemplos en el documento A/CN.9/WG.V/WP.95, párrs. 15 y 16.

intereses del deudor en el momento de iniciarse el procedimiento (la cuestión del momento de la determinación del centro de los principales intereses se analiza en los párrs. 128A a E *infra*). A pesar del propósito diferente del centro de los principales intereses en los dos instrumentos, la jurisprudencia relativa a la interpretación de ese concepto en el Reglamento CE podría ser pertinente para su interpretación en la Ley Modelo.

123B. La presunción establecida en el párrafo 3 del artículo 16 ha dado lugar a considerable análisis, más en el contexto de los deudores empresariales que en el de los individuales, análisis que se ha centrado en las pruebas requeridas para impugnar la presunción. Probablemente, el centro de los principales intereses del deudor será su domicilio social, en cuyo caso no habrá motivo de impugnación de la presunción.

123C. No obstante, cuando un representante extranjero solicita el reconocimiento de un procedimiento extranjero como procedimiento principal y parezca haber una distinción entre el domicilio social del deudor y el presunto centro de sus principales intereses, la parte que alegue que el centro de los principales intereses no es el domicilio social deberá probar al tribunal la ubicación del centro de los principales intereses. El tribunal del Estado promulgante deberá considerar por sí mismo la ubicación del centro de los principales intereses del deudor.

Centro de los principales intereses

123D. El concepto de centro de los principales intereses del deudor es fundamental para el funcionamiento de la Ley Modelo²¹. Esta asigna más importancia a los procedimientos abiertos en ese lugar y prevé medidas otorgables más inmediatas de establecimiento automático. Los atributos esenciales del centro de los principales intereses del deudor se corresponden con los atributos que permitirán a quienes hagan negocios con él (especialmente a los acreedores) averiguar el lugar en que es probable se abra el procedimiento de insolvencia relativo al deudor. Como ya se ha indicado, en la Ley Modelo se establece la presunción de que el lugar que corresponde a esos atributos es el domicilio social del deudor. Sin embargo, en realidad, el centro de los principales intereses del deudor puede no coincidir siempre con su domicilio social, y la Ley Modelo prevé la posibilidad de impugnar esa presunción cuando el centro de los principales intereses esté situado en un lugar distinto al domicilio social. Cuando no se tenga la certidumbre de que el domicilio social del deudor es el centro de sus principales intereses, este se determinará sobre la base de otros factores que indiquen a los que hacen negocios con el deudor (especialmente los acreedores) dónde está el centro de los principales intereses. Así pues, es importante tener en cuenta los factores que por sí solos puedan indicar que el centro de los principales intereses del deudor es un determinado Estado.

Factores pertinentes para determinar el centro de los principales intereses

123F. En la mayoría de los casos, los factores principales que se exponen a continuación, considerados globalmente, tenderán a indicar si el lugar en el que se abrió el procedimiento extranjero es el centro de los principales intereses del deudor. Esos factores son los siguientes: a) si el lugar es fácil de averiguar para los

²¹ Como se indicó en el párrafo 31A, el concepto de centro de los principales intereses es también básico en el régimen establecido en el Reglamento CE.

acreedores, y b) si es el lugar en que se lleva a cabo la administración central del deudor.

123G. Cuando esos principales factores no se presten para determinar fácilmente el centro de los principales intereses del deudor, podrán considerarse otros en relación con los negocios del deudor. Tal vez el tribunal tenga que asignar una mayor o menor importancia a un determinado factor, según las circunstancias del caso de que se trate. No obstante, en todos los casos el proceso ha de considerarse integral y está destinado a determinar que el lugar del procedimiento extranjero se corresponde efectivamente con el del centro de los principales intereses del deudor.

123I. El orden en el que se enumeran a continuación los otros factores no pretende indicar la prioridad o importancia que ha de darse a cada uno de ellos, ni tampoco se pretende que se trate de una lista exhaustiva de los factores pertinentes; el tribunal podría considerar aplicables otros factores en un caso determinado. Entre esos otros factores cabe citar los siguientes: el lugar en que se encuentran los libros de contabilidad y los registros del deudor; el lugar en el que se organizaba o autorizaba la financiación o se administraba el sistema de gestión del efectivo; el lugar en que se hallan los activos u operaciones principales del deudor; el lugar en que se encuentra el banco principal del deudor; el lugar en el que estaban sus empleados; el lugar en el que se determinaba la política comercial; la jurisdicción de la legislación de control o de la legislación por la que se regían los principales contratos de la empresa; el lugar desde el que se gestionaba la política de compras y ventas, el personal, las cuentas a pagar y los sistemas informáticos; el lugar en el que se organizaban los contratos (de suministro); el lugar desde el que se dirigía la reorganización de la empresa del deudor; la jurisdicción cuya legislación se aplicaba a la mayoría de los litigios; el lugar en el que el deudor era objeto de supervisión o reglamentación, y el lugar por cuya legislación se regía la preparación y auditoría de las cuentas y en el que estas se preparaban y auditaban.

Traslado del centro de los principales intereses

123K. El centro de los principales intereses del deudor puede trasladarse antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, en algunos casos en fecha muy próxima a esa apertura e incluso entre el momento de la solicitud de apertura y la apertura efectiva del procedimiento²². Siempre que haya pruebas de que se ha realizado un traslado en fecha muy próxima a la apertura del procedimiento extranjero, puede ser conveniente que el tribunal ante el que se recurra, al determinar si reconoce o no el procedimiento, considere más detenidamente los factores indicados en los párrafos 123F y 123I *supra* y tenga en cuenta las circunstancias del deudor de manera más general. En particular, la condición de que los terceros puedan averiguar fácilmente cuál es el centro de los principales intereses será más difícil de cumplir si el traslado de este ha tenido lugar en una fecha muy próxima a la apertura del procedimiento.

²² [En algunos ejemplos, el traslado tenía por objeto dar acceso al deudor a un proceso de insolvencia -por ejemplo, de reorganización- que atendiera en mayor medida sus necesidades que el que le ofrecía la legislación de la jurisdicción en la que se encontraba su anterior centro de los principales intereses. En otros casos, el traslado del centro de los principales intereses podría haber estado encaminado a frustrar las expectativas legítimas de los acreedores y terceros o haberse llevado a cabo aprovechando información confidencial o por motivos subjetivos.]

123M. No es probable que un deudor pueda trasladar su domicilio social (o su residencia habitual) tras la apertura del procedimiento de insolvencia, ya que en muchos casos el régimen de la insolvencia contiene disposiciones especiales para impedirlo. En cualquier caso, si eso ocurriera, no afectaría a la decisión sobre el centro de los principales intereses a efectos de la Ley Modelo, ya que la fecha que se ha de tener en cuenta para determinarlo es la de la apertura del procedimiento extranjero (véanse los párrs. 128A a C *infra*).

Artículo 17. Resolución de reconocimiento de un procedimiento extranjero

Párrafo 1

124. Después de las palabras “Estado promulgante” se ha añadido la referencia “(véase el artículo 6)”.

124A. Al decidir si otorga o no el reconocimiento de un procedimiento extranjero, el tribunal ante el que se recurra estará limitado por los requisitos jurisdiccionales enunciados en la definición. Esto exige determinar si el procedimiento es un procedimiento extranjero de conformidad con el inciso a) del artículo 2. La Ley Modelo no prevé que el tribunal ante el que se recurra proceda a examinar si el procedimiento extranjero se abrió correctamente de conformidad con el derecho aplicable; siempre que el procedimiento satisfaga los requisitos estipulados en el artículo 15 y no sea pertinente el artículo 6, deberá otorgarse el reconocimiento de conformidad con el artículo 17.

124B. Al adoptar su decisión sobre el reconocimiento, el tribunal ante el que se recurra podrá tener debidamente en cuenta todas las decisiones y órdenes del tribunal que abrió el procedimiento y toda información que pueda haberse presentado a dicho tribunal. Esas órdenes o decisiones no son vinculantes para el tribunal ante el que se recurra en el Estado promulgante, que debe cerciorarse por sí mismo de que el procedimiento extranjero satisface los requisitos del artículo 2. No obstante, el tribunal puede basarse, de conformidad con las presunciones establecidas en los párrafos 1 y 2 del artículo 16 (véase el párr. ...), en la información que figure en los certificados y documentos presentados en apoyo de la solicitud de reconocimiento. En circunstancias apropiadas, esa información contribuirá a las deliberaciones de dicho tribunal.

124C. En consecuencia, el reconocimiento del procedimiento extranjero se facilitaría si el tribunal que abrió el procedimiento mencionara en sus órdenes cualquier información que permitiera decidir al tribunal ante el que se recurra que el procedimiento es un procedimiento extranjero en el sentido del artículo 2. Ello sería especialmente útil cuando el tribunal que abrió el procedimiento conociera el carácter internacional del deudor o sus negocios y la probabilidad de que se solicitara el reconocimiento del procedimiento en el marco de la Ley Modelo. Las mismas consideraciones serían aplicables al nombramiento y reconocimiento del representante extranjero.

Párrafo 2

126 a 128. [...]

Momento de la determinación del centro de los principales intereses y el establecimiento

128A. La Ley Modelo no indica explícitamente el momento pertinente para determinar el centro de los principales intereses del deudor.

128B. En el artículo 17, párr. 2, inciso a), se dispone que el procedimiento extranjero se reconocerá como procedimiento principal “si *se está tramitando* en el Estado donde el deudor *tenga* el centro de sus principales intereses” [*cursivas añadidas*]. El uso del tiempo presente en el artículo 17 no resuelve la cuestión del momento pertinente sino que exige que el procedimiento extranjero esté en curso o pendiente en el momento de adoptarse la decisión sobre el reconocimiento; si en ese momento el procedimiento respecto del cual se solicita el reconocimiento no está ya en curso ni pendiente en el Estado en el que se procedió a su apertura (es decir, si ya no “se está tramitando” porque se le puso fin o se cerró), no existe ningún procedimiento susceptible de reconocimiento en virtud de la Ley Modelo.

128C. Con respecto a la fecha en que ha de determinarse el centro de los principales intereses del deudor, habida cuenta de las pruebas que han de presentarse junto con la solicitud de reconocimiento, de conformidad con el artículo 15, y de la importancia asignada a la resolución por la que se declara abierto el procedimiento extranjero y se nombra al representante extranjero, la fecha de apertura de ese procedimiento es la fecha adecuada²³. Cuando la actividad comercial del deudor cese después de la apertura del procedimiento extranjero, lo único que podrá haber en el momento de la solicitud de reconocimiento que indique el centro de los principales intereses del deudor será el procedimiento extranjero y la actividad del representante extranjero en relación con la administración de la masa de la insolvencia. En ese caso, la determinación del centro de los principales intereses del deudor por referencia a la fecha de la apertura de ese procedimiento tendría un resultado claro. Puede aplicarse también el mismo razonamiento en el caso de una reorganización, en el que, con arreglo a algunas legislaciones, no es el deudor el que sigue teniendo un centro de los principales intereses, sino la entidad encargada de la reorganización. En tal caso, se satisface claramente el requisito de un procedimiento extranjero que se está tramitando de conformidad con el artículo 17, párrafo 2, inciso a), y el procedimiento extranjero podría obtener el reconocimiento. Además, tomar la fecha de apertura como base para determinar el centro de los principales intereses constituye un criterio que puede aplicarse con certeza en todos los procedimientos de insolvencia.

128D. El mismo razonamiento puede aplicarse al momento en el que debe formularse una determinación con respecto a la existencia de un establecimiento del deudor. Por consiguiente, la fecha de la apertura del procedimiento extranjero es la fecha que ha de tenerse en cuenta al formular esa determinación.

²³ En algunos regímenes de la insolvencia, los efectos de la apertura se retrotraen a la fecha de la solicitud de apertura, o la fecha de la solicitud pasa a ser automáticamente la de la apertura. En ambos casos conviene tener en cuenta la fecha de la apertura para la determinación del centro de los principales intereses, ya que la Ley Modelo solo se ocupa del procedimiento extranjero existente y del momento en que se inició.

Abuso del proceso

123J. Una cuestión que ha surgido con respecto a la solicitud de reconocimiento es si el tribunal debería poder tener en cuenta que se está cometiendo un abuso del proceso como fundamento para denegar el reconocimiento. Ninguna disposición de la Ley Modelo de la CNUDMI sugiere por sí misma que cuando se solicite un reconocimiento deban tenerse en cuenta circunstancias externas. La Ley Modelo prevé que la respuesta a la solicitud venga determinada por los criterios concretos establecidos en las definiciones de “procedimiento extranjero”, “procedimiento extranjero principal” y “procedimiento extranjero no principal”. Dado que lo que constituye abuso del proceso depende de la legislación o las normas procesales internas, la Ley Modelo no impide expresamente que los tribunales ante los que se recurra apliquen la legislación interna o las normas procesales para hacer frente a un abuso del proceso que hayan podido observar. No obstante, debe tenerse presente la finalidad más amplia de la Ley Modelo, a saber, la de promover la cooperación internacional como medio de optimizar los resultados para todos los interesados, establecida en el artículo 1, así como los orígenes internacionales de la Ley Modelo y la necesidad de promover su aplicación uniforme, como se dispone en el artículo 8. Los tribunales que consideren la posibilidad de aplicar las leyes y normas procesales internas podrían recordar también que la excepción de orden público prevista en el artículo 6 (véanse los párrs. 86 a 89 *supra*) ha de interpretarse en sentido estricto e invocarse únicamente cuando la adopción de una medida con arreglo a la Ley Modelo sea manifiestamente contraria al orden público de un Estado. Como regla general, el artículo 6 muy raramente podría servir de base para denegar el reconocimiento, si bien sí podría servir de base para limitar la naturaleza de las medidas otorgables.

123L. Si el solicitante declara con falsedad que el centro de los principales intereses se encuentra en un determinado Estado, el tribunal ante el que se recurra podrá determinar que se ha incurrido en abuso deliberado del proceso. La Ley Modelo no impide que dicho tribunal aplique las leyes o las normas procesales internas para hacer frente a ese abuso del proceso.

Párrafo 3

125. La prontitud con la que el representante extranjero consiga su reconocimiento (y el subsiguiente derecho a invocar en particular los artículos 20, 21, 23 y 24) suele ser esencial para poder proteger los bienes del deudor de cualquier tentativa de dispersión u ocultación. Por ello, en el párrafo 3 se exige que el tribunal decida sobre la solicitud “a la mayor brevedad posible”. La expresión “a la mayor brevedad posible” tiene cierta elasticidad. Puede haber casos que sean tan claros que el proceso de reconocimiento pueda realizarse en unos días. En otros casos, particularmente cuando se impugne el reconocimiento, “a la mayor brevedad posible” podría significar meses. Cuando sea necesario dictar una orden mientras esté pendiente la resolución sobre la solicitud de reconocimiento se otorgarán las medidas oportunas con carácter provisional.

Párrafo 4

129. Toda decisión de reconocer un procedimiento extranjero podrá normalmente reconsiderarse y revocarse, al igual que cualquier otra decisión judicial. El párrafo 4 aclara que podrá reconsiderarse el reconocimiento si se demuestra una ausencia total

o parcial de motivos para haberlo concedido o si, de haber habido tales motivos, han dejado de existir.

130. La modificación o revocación de la decisión de reconocimiento puede ser consecuencia de un cambio de circunstancias posterior a su adopción, como la terminación del procedimiento extranjero reconocido o un cambio de su naturaleza (por ejemplo, si un procedimiento de reorganización pasa a ser de liquidación), o de que la situación del nombramiento del representante extranjero haya variado o el nombramiento haya terminado. Pueden también surgir nuevos hechos que requieran un cambio de la decisión del tribunal o lo justifiquen: por ejemplo, si el representante extranjero ha hecho caso omiso de las condiciones impuestas por el tribunal al otorgar las correspondientes medidas. La obligación que impone el artículo 18 al representante extranjero de informar al tribunal de un cambio de las circunstancias refuerza la capacidad del tribunal para reconsiderar la decisión de reconocimiento.

131. [No se aplica en español.]

Notificación de la decisión de reconocimiento de un procedimiento extranjero

132. [...]

Artículo 18. Información subsiguiente

Inciso a)

133. El artículo 18 impone al representante extranjero la obligación de informar con prontitud al tribunal de “todo cambio importante en la situación del procedimiento extranjero reconocido o en el nombramiento del representante extranjero” que se haya producido tras la presentación de la solicitud de reconocimiento del procedimiento extranjero. La finalidad de esa obligación es permitir que el tribunal modifique las consecuencias del reconocimiento o les ponga término. Como se indicó *supra*, es posible que, una vez presentada la solicitud de reconocimiento u otorgado el reconocimiento, se produzcan cambios en el procedimiento extranjero que habrían afectado a la decisión de otorgarlo o de otorgar medidas sobre la base del reconocimiento: por ejemplo, la terminación del procedimiento extranjero o su conversión de un tipo de procedimiento a otro. En el inciso a) se tiene en cuenta que es frecuente que se produzcan cambios técnicos en la situación del procedimiento o en el nombramiento del representante extranjero, pero que solo algunos de esos cambios afectarían a la decisión relativa a las medidas otorgables o a la de reconocer el procedimiento; por consiguiente, la disposición se limita a exigir que se informe de todo cambio “importante”. Es especialmente importante que el tribunal esté informado de esas modificaciones cuando su decisión de reconocimiento se refiera a un procedimiento extranjero “de índole provisional” o a un representante extranjero nombrado “a título provisional” (véase el artículo 2, incisos a) y d)).

Inciso b)

134. Se han añadido las palabras “y facilitará la cooperación de conformidad con el capítulo IV” al final del párrafo.

Párrafos 1 a 4

135 a 140. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 135 a 140.

Artículo 20. Efectos del reconocimiento de un procedimiento extranjero principal

141. Al final del párrafo se ha añadido la siguiente oración: “Los artículos 14, 23 y 24 contienen otros efectos del reconocimiento.”

142. [...]

143. El principio de la segunda oración debe decir: “Para lograr esos beneficios, se justifica la imposición al deudor insolvente de los efectos del artículo 20 en el Estado promulgante (es decir, un Estado en el que la presencia comercial del deudor es limitada)...”. La última oración debe decir: “Si, en un caso dado, el reconocimiento ocasiona resultados contrarios al legítimo interés de alguna parte, incluido el deudor, la ley del foro debería incluir medios adecuados de protección, conforme se indica en el párrafo 2 del artículo 20 (y se examina en el párrafo 149 *infra*).”

144 a 146. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 144 a 146.

147 y 148. [...]

149. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 149.

150. [...]

151 a 153. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 151 a 153.

Artículo 21. Medidas otorgables a partir del reconocimiento de un procedimiento extranjero

154. Además de las medidas imperativas de paralización y suspensión establecidas en el artículo 20, la Ley Modelo autoriza al tribunal a otorgar, después del reconocimiento de un procedimiento extranjero, medidas que redunden en beneficio de ese procedimiento. Las medidas otorgables en virtud del artículo 21 después del reconocimiento son discrecionales, como lo son también las otorgables antes del reconocimiento en virtud del artículo 19. En el párrafo 1 del artículo 21 se indican las medidas típicas o habituales de un procedimiento de insolvencia, pero esa lista no es exhaustiva, por lo que no limita innecesariamente la capacidad del tribunal para otorgar cualquier otra medida aplicable con arreglo a la ley del foro que sea necesaria en las circunstancias del caso.

155. [...]

156. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 156.

157. [...]

158. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 158.

159. [...]

160. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 160.

Artículo 22. Protección de los acreedores y de otras personas interesadas

161. [...]

162 a 164. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 162 a 164.

Artículo 23. Acciones de impugnación de actos perjudiciales para los acreedores

165. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 165 y 166.

166. La Ley Modelo dispone expresamente que, como efecto del reconocimiento del procedimiento extranjero de conformidad con el artículo 17, un representante extranjero estará legitimado¹⁹ para entablar acciones en virtud de la ley del foro destinadas a anular o dejar por algún otro concepto sin efecto todo acto jurídico en perjuicio de los acreedores. La disposición ha sido redactada en términos restrictivos, ya que no crea ningún derecho sustantivo respecto de esas acciones ni ofrece una solución ante un posible conflicto de leyes; la Ley Modelo no aborda la cuestión del derecho de un representante extranjero a interponer una acción de esta índole en el Estado promulgante con arreglo al derecho interno del Estado en que tiene lugar el procedimiento extranjero. El efecto del artículo 17 consiste en que no se impedirá que un representante extranjero entable esas acciones por el solo hecho de que no sea el representante de la insolvencia nombrado en el Estado promulgante.

166A. Cuando el procedimiento extranjero haya sido reconocido como “procedimiento no principal”, el tribunal deberá asegurarse en concreto de que la acción que pueda entablarse al amparo de las disposiciones del artículo 23 afecta a bienes que “deban ser administrados en el marco del procedimiento extranjero no principal” (artículo 23, párr. 2)). Una vez más se distingue la naturaleza de un procedimiento “principal” de la de un procedimiento “no principal” y se subraya que es probable que las medidas otorgables con respecto a un procedimiento “no principal” sean más restrictivas que las otorgables con respecto a un procedimiento “principal”.

167. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 167.

Artículo 24. Intervención de un representante extranjero en procedimientos que se sigan en este Estado

168 y 169. [...]

170. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 170.

171 y 172. [...]

Capítulo IV. Cooperación con tribunales y representantes extranjeros

38 y 39. [...]

173. [...]

173A. La cooperación no depende del reconocimiento y por lo tanto puede tener lugar en una etapa temprana y antes de la solicitud de reconocimiento. Dado que los artículos del capítulo IV se aplican a las cuestiones que se mencionan en el artículo 1, se puede obtener no solo con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas en el Estado promulgante, sino también a las solicitudes en relación con un procedimiento que se esté tramitando en el Estado promulgante con fines de prestación de asistencia en el extranjero (véase también el artículo 5). La cooperación no se limita a los procedimientos extranjeros en el sentido del artículo 2, inciso a), que los habilitaría para el reconocimiento de conformidad con el artículo 17 (es decir, independientemente de que sean principales o no principales), por lo cual la cooperación podrá obtenerse con respecto a procedimientos iniciados sobre la base de la presencia de bienes. Una disposición de este tipo puede ser útil cuando el procedimiento se abre en el Estado promulgante y se solicita asistencia en el extranjero. Esa disposición también puede ser pertinente cuando el Estado promulgante tenga otras leyes, además de la Ley Modelo, que faciliten la coordinación y cooperación con procedimientos extranjeros (véase el artículo 7).

174 a 178. [...]

Artículo 25. Cooperación y comunicación directa entre un tribunal de este Estado y los tribunales o representantes extranjeros

179 y 180. [...]

181. Se sugiere que el Estado promulgante se sirva del artículo 27 para facilitar a los tribunales una lista indicativa de las formas de cooperación autorizadas por los artículos 25 y 26. Esa lista indicativa podría ser particularmente útil en Estados que no tengan demasiada tradición de cooperación transfronteriza directa entre los tribunales y en Estados que tradicionalmente limiten la discrecionalidad de los tribunales; y, por ser indicativa, deja al legislador la posibilidad de enumerar otras formas de cooperación. Toda lista de formas posibles de cooperación deberá ser ilustrativa y no exhaustiva, para evitar la exclusión involuntaria de algunas formas apropiadas de cooperación y la restricción de la capacidad de los tribunales para idear recursos en armonía con circunstancias concretas.

182. [...]

183. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 183.

183A. La Guía de Prácticas de la CNUDMI sobre Cooperación en la Insolvencia Transfronteriza contiene más detalles sobre las formas de cooperación mencionadas en el artículo 27 y, en particular, recopila las prácticas y la experiencia adquirida en relación con el uso de acuerdos sobre insolvencia transfronteriza²⁴.

²⁴ Véase la nota 8.

Capítulo V. Procedimientos paralelos

Artículo 28. Apertura de un procedimiento con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia] tras el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal

184. Al principio del párrafo se ha insertado la siguiente oración: “La Ley Modelo apenas impone limitaciones a la competencia de un tribunal del Estado promulgante para declarar abierto o proseguir un procedimiento de insolvencia.”

185. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párr. 185.

186. Como nueva segunda oración se ha añadido la siguiente: “La adopción de una limitación de este tipo no sería contraria a los principios en que se inspira la Ley Modelo.”

187. [...]

187A. En los casos en que con arreglo a la ley del foro el deudor deba ser insolvente a efectos de abrir un procedimiento de insolvencia, la Ley Modelo establece una presunción impugnabile de que el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal constituye prueba suficiente de que el deudor es insolvente a esos efectos (artículo 31) (véanse los párrs. 194 a 197).

Artículo 29. Coordinación de un procedimiento seguido con arreglo a [indíquese la norma de derecho interno relativa a la insolvencia] y un procedimiento extranjero

188. Como nueva segunda oración se ha añadido la siguiente: “El objetivo de este artículo y del artículo 30 es favorecer la adopción de decisiones coordinadas que permitan lograr mejor los objetivos de ambos procedimientos (por ejemplo, optimizar el valor de los bienes del deudor o reorganizar lo más ventajosamente posible la empresa).”

189 a 191. [...]

Artículo 30. Coordinación de varios procedimientos extranjeros

192 y 193. [...]

Artículo 31. Presunción de insolvencia basada en el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal

194 a 196. [...]

197. Al principio del párrafo se ha insertado la siguiente oración: “Sin embargo, esta regla sería útil en ordenamientos en los que se haya de probar la insolvencia del deudor antes de abrir un procedimiento de insolvencia.”

Artículo 32. Regla de pago para procedimientos paralelos

198 a 200. [...]

VI. Asistencia de la Secretaría de la CNUDMI

201 y 202. Con respecto a modificaciones editoriales de menor importancia, véase el documento A/CN.9/WG.V/WP.107, párrs. 201 y 202.

H. Nota de la Secretaría sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43º período de sesiones

(A/CN.9/WG.V/WP.113)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
Introducción.	1-8
Obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia	
Introducción y finalidad de esta [parte]	
I. Contexto	1-15
II. Elementos de las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia	16-57
A. La naturaleza de las obligaciones.	16-21
B. Cuándo nacen las obligaciones: el período cercano a la insolvencia	22-25
C. Determinación de las partes en las que recaen las obligaciones	26-29
D. Responsabilidad.	30-36
E. Ejecución de las obligaciones de los directores respecto a la apertura de un procedimiento de insolvencia	37-57

Introducción

1. En su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión tuvo a su disposición varias propuestas para una labor futura sobre el régimen de la insolvencia (documentos A/CN.9/WG.V/WP.93 y Add.1 a 6 y A/CN.9/582/Add.6). Esas propuestas habían sido examinadas por el Grupo de Trabajo V en su 38º período de sesiones (véase A/CN.9/691, párrs. 99 a 107), ocasión en que se recomendaron a la Comisión posibles temas de estudio (A/CN.9/691, párr. 104). Con posterioridad a ese período de sesiones del Grupo de Trabajo V, se presentó otro documento (A/CN.9/709) con material complementario de la propuesta de Suiza que figuraba en el documento A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.5.

2. Después de sus deliberaciones, la Comisión apoyó la recomendación del Grupo de Trabajo V que figuraba en el documento A/CN.9/691, párrafo 104, de que se emprendieran actividades sobre dos temas relacionados con la insolvencia, que tenían importancia en la actualidad y en los que una mayor armonización de las reglamentaciones de los distintos Estados aportaría mayor certeza y previsibilidad.

3. El objeto de la presente nota es el segundo tema, propuesto por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.4), la Federación Internacional de Profesionales en materia de Insolvencia (INSOL International) (A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.3) y el International Insolvency Institute

(A/CN.9/582/Add.6), relativo a la responsabilidad y las obligaciones de los directores y ejecutivos de una empresa en situación de insolvencia o previa a la insolvencia¹. Dadas las inquietudes planteadas durante el extenso debate la Comisión convino en que, en relación con este tema, se trataría únicamente la responsabilidad y las obligaciones que nacieran en el contexto de la insolvencia sin pretender abarcar aspectos de la responsabilidad penal ni cuestiones estrictamente del ámbito de la legislación sobre sociedades.

4. El examen de este tema comenzó en el 39º período de sesiones del Grupo de Trabajo (celebrado en diciembre de 2010 en Viena) y continuó en los períodos de sesiones 40º, 41º y 42º de ese Grupo (celebrados del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2011 en Viena; del 30 de abril al 4 de mayo de 2012 en Nueva York; y del 26 al 30 de noviembre de 2012 en Viena). Las deliberaciones y conclusiones del Grupo de Trabajo figuran en los informes de esos períodos de sesiones (A/CN.9/715, A/CN.9/738, A/CN.9/742 y A/CN.9/763, respectivamente).

5. El material que figura a continuación se basa en los documentos A/CN.9/WG.V/WP.96, 100, 104 y 108, así como en las decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo en sus períodos de sesiones 39º, 40º, 41º y 42º. Para facilitar la consulta se ha conservado en la presente nota entre corchetes el número de párrafo y de recomendación empleados en las versiones anteriores del texto (a saber, A/CN.9/WG.V/WP.104 y 108).

6. De conformidad con la hipótesis de trabajo adoptada por el Grupo de Trabajo en su 41º período de sesiones (A/CN.9/742, párr. 74) de que la labor formaría parte de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia, el texto que figura a continuación sigue el formato de la Guía Legislativa. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si debe ser una parte nueva de la Guía o si puede incluirse como una sección nueva de una parte ya existente, por ejemplo el capítulo III de la segunda parte (Participantes). De acuerdo con una solicitud formulada en el 42º período de sesiones, el orden del comentario refleja ahora el orden de las recomendaciones y las recomendaciones ya no aparecen todas juntas al final del texto, sino que van a continuación de las partes correspondientes del comentario. Cada conjunto de recomendaciones lleva como introducción una cláusula sobre la finalidad, en consonancia con las partes primera a tercera de la Guía.

7. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar también si se deberían incluir en un glosario para esta [parte] algunos términos específicos.

8. El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que en los párrafos que se mencionan a continuación figura texto nuevo entre corchetes para su examen: Introducción y finalidad, párrafos 1 y 2; Contexto, párrafo 2; sección II, párrafos 20 d), f), j), 21, 21A, 22, 25, 33, 35, 36, 47, 48, 51, 55 y 57. Las cláusulas sobre finalidad de los proyectos de recomendación 3 a 12 se presentan para su examen, así como algunos términos de los proyectos de recomendación 1, 3, 6, 8 y el proyecto de recomendación 12 y la nota de pie de página asociada.

¹ El primer tema, relativo al centro de los principales intereses y cuestiones conexas se examina en el documento A/CN.9/WG.V/WP.112.

Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia

Obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia

Introducción y finalidad de esta [parte]

[1. Esta [parte] se centra en las obligaciones que se podrían imponer a los responsables de adoptar decisiones con respecto a la administración de una empresa cuando esa empresa se enfrenta a una insolvencia inminente o la insolvencia se hace inevitable. El propósito de imponer esas obligaciones, que serían exigibles una vez que se hubiera iniciado el procedimiento de insolvencia, es proteger los intereses legítimos de los acreedores y demás interesados y alentar a que se actúe con prontitud para minimizar los efectos de las dificultades financieras que atraviesa la empresa. La constitución de una junta directiva es un factor importante para hacer frente a los problemas. Generalmente, está formada por personas que tienen derechos de propiedad sobre la empresa y personas que trabajan para ella, por ejemplo gestionando sus operaciones comerciales, o tienen alguna conexión con sus accionistas (“directores internos”), junto con personas que son independientes y con frecuencia son seleccionadas como consecuencia de su experiencia y su visión para los negocios (“directores independientes”). Los directores independientes pueden no tener acceso a la misma cantidad de información que conocen o tienen a su disposición los directores internos, los acreedores o los terceros. La responsabilidad de los directores internos e independientes puede ser distinta, según las circunstancias del caso.]

[2. Se tratan los elementos esenciales de las disposiciones que imponen esas obligaciones; a saber: a) la naturaleza y el alcance de las obligaciones; b) cuándo deberían nacer las obligaciones; c) las personas en las que recaerían las obligaciones; d) la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones; e) la ejecución de esas obligaciones; f) las defensas aplicables; g) los recursos; h) las personas que pueden entablar una demanda para exigir el cumplimiento de las obligaciones; e i) cómo se podrían financiar esas demandas.]

I. Contexto

1. [6] Los marcos de gobernanza de las empresas regulan una serie de relaciones entre los directivos de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otros interesados, y proporcionan no solo la estructura a través de la cual se establecen y cumplen los objetivos de la empresa, sino también las normas que permiten controlar su desempeño. Una buena gobernanza empresarial debería ofrecer incentivos para que el consejo de administración y los directivos de la empresa persigan objetivos que redunden en beneficio de esta y de sus accionistas, y fomentar la confianza necesaria para promover la inversión y el desarrollo de la empresa. Es mucho lo que se ha hecho a nivel internacional para elaborar principios

de buena gestión empresarial², ampliamente adoptados, que abarcan las obligaciones de las personas encargadas de adoptar decisiones sobre la administración de una empresa (en esta [parte], denominados “directores”)³ cuando la empresa es solvente.

2. [7] Una vez iniciado un procedimiento de insolvencia, sin embargo, muchos regímenes de la insolvencia reconocen que las obligaciones de los directores serán diferentes, en cuanto al fondo y al enfoque principal, de las aplicables antes de la apertura de ese procedimiento, y se centrarán prioritariamente en obtener el máximo valor de los bienes y en preservar la masa para su distribución a los acreedores. En muchos casos los directores serán apartados de la participación continua en los asuntos de la empresa por un representante de la insolvencia, aunque en virtud de algunos regímenes de la insolvencia pueden seguir desempeñando un papel continuo, especialmente en la reorganización. [La recomendación 112 se ocupa de las diversas posibilidades que puede desempeñar el deudor cuando se mantenga en marcha la empresa, a saber, mantener el pleno control, ser privado parcialmente de sus funciones y ser removido totalmente.] Las obligaciones de los directores una vez iniciado un procedimiento de insolvencia se tratan más arriba, en las recomendaciones 108 a 114 y en el comentario de la segunda parte, capítulo III, párrafos 22 a 34. En la recomendación 110 se especifican con cierto detalle las obligaciones que deberían nacer en virtud del régimen de la insolvencia al abrirse el procedimiento de insolvencia y ser exigibles hasta su clausura; entre ellas figuran las de cooperar con el representante de la insolvencia y ayudarlo a desempeñar sus funciones; facilitar toda información exacta, fidedigna y completa sobre la situación financiera de la empresa y el estado de su negocio; y cooperar con el representante de la insolvencia y prestarle asistencia para que pueda asumir eficazmente el control de la masa y para facilitar la recuperación de los bienes y los registros de la empresa. También se prevé la imposición de sanciones a todo deudor que incumpla estas obligaciones (recomendación 114 y párrafos 32 a 34 del comentario).

3. [8] Los regímenes de la insolvencia eficaces, además de establecer un proceso jurídico previsible para hacer frente a las dificultades financieras de las empresas con problemas y el marco necesario para su reorganización eficiente o una liquidación ordenada, deberían permitir también la realización de un examen de las circunstancias que dieron lugar a la insolvencia y, en particular, de la conducta de los directores de la empresa en el período anterior al comienzo del procedimiento de insolvencia. Ahora bien, poco se ha hecho a nivel internacional para armonizar los distintos enfoques de las legislaciones nacionales con vistas a facilitar el examen de esa conducta, y sigue habiendo divergencias importantes. No están claramente establecidos el carácter ni el alcance de las obligaciones que puedan tener los directores en un período en que la empresa pueda tener problemas financieros sin ser todavía insolvente o ser objeto del procedimiento de insolvencia, pero están siendo objeto de un creciente debate, especialmente en vista de las múltiples quiebras ocurridas como consecuencia de la crisis financiera mundial de 2008.

² Véanse, por ejemplo, los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, 2004.

³ La cuestión de quién puede ser considerado director a los efectos de esta [parte] se examina más abajo en los párrs. ... Si bien no existe una definición universalmente aceptada del término, por comodidad en la presente parte nos referimos generalmente a “directores”.

4. [9] Una empresa que se ve en la imposibilidad efectiva o inminente de cumplir sus obligaciones financieras y contractuales cuando vencen los plazos necesita una gestión robusta, ya que a menudo hay juicios y decisiones difíciles que adoptar que serán decisivos para la supervivencia de la empresa, con los consiguientes beneficios para sus dueños, acreedores, clientes, empleados y demás interesados. Los directores competentes deberían entender la situación financiera de la empresa y poseer toda la información que sea razonablemente posible para poder adoptar las medidas necesarias a fin de hacer frente a la dificultad financiera y evitar un empeoramiento de la situación. En esos momentos, los directores deben elegir el curso de acción que mejor responda a los intereses de la empresa en su conjunto, tras haber sopesado los intereses de las partes interesadas correspondientes en las circunstancias concretas del caso. En algunos regímenes esas partes interesadas serán la propia sociedad y sus accionistas. En otros regímenes puede tratarse de una comunidad de intereses más amplia que incluya a los acreedores. Un director preocupado por su responsabilidad personal y las posibles repercusiones financieras de la adopción de decisiones difíciles en esas circunstancias puede cerrar prematuramente una empresa en lugar de intentar resolver las dificultades, puede incurrir en comportamientos indebidos, como la disposición impropia de los bienes o el patrimonio, o también puede sentirse tentado de renunciar, lo que a menudo aumenta las dificultades que tiene la sociedad.

5. [9 A] No les es fácil a los directores ni a los directivos lograr un equilibrio entre los diferentes intereses y motivaciones de las partes interesadas, los cuales pueden convertirse en una fuente de conflicto. Por ejemplo, los accionistas de la empresa, que generalmente tienen pocas posibilidades de participar en una distribución que se realice en el procedimiento de insolvencia, están interesados en mejorar su propia posición tratando de negociar una salida de la insolvencia o resistirse a una posible venta con la esperanza de obtener un mayor beneficio, especialmente si el precio de la venta solo bastaría para pagar los créditos de los acreedores y no dejaría nada a los accionistas. Esta forma de actuar puede entrañar la adopción de estrategias de alto riesgo con el fin de ahorrar o de aumentar el valor para los accionistas, comprometiendo al mismo tiempo los intereses de los acreedores. También puede ser reflejo de una escasa preocupación por las posibilidades de éxito, debido a la protección de la responsabilidad limitada o de un seguro por responsabilidad del director si el curso de acción adoptado fracasa.

6. [10] A pesar de las dificultades que puede entrañar la adopción de decisiones empresariales acertadas, cuando una empresa afronta dificultades financieras es esencial comenzar a actuar lo antes posible. Normalmente, la degradación financiera avanza con más rapidez de lo que muchos podrían suponer y, a medida que empeora la situación financiera de la empresa, las opciones disponibles para lograr una solución viable también disminuyen rápidamente. Esta acción temprana debe verse facilitada por un acceso inmediato a los procedimientos pertinentes; de poco sirve exigir a los directores que actúen prontamente si no se les da la posibilidad de recurrir a procedimientos pertinentes y eficaces⁴. Además, los regímenes que exponen a los directores a responsabilidad por las operaciones que realicen mientras estén en curso procedimientos oficiosos tales como las negociaciones de

⁴ Se ha sugerido que la escasez de casos sometidos al régimen de la insolvencia en un Estado se debe a la relativa facilidad de acceso a procedimientos voluntarios, por lo que solo terminan liquidándose las empresas que son irremediamente insolventes.

reestructuración (examinadas en la primera parte, capítulo II, párrafos 2 a 18) pueden desincentivar la adopción de medidas tempranas. Si bien en muchos países los regímenes de la insolvencia se han reajustado debidamente para incrementar las opciones de una acción temprana con el fin de facilitar el rescate y la reorganización de las empresas, se ha prestado poca atención a brindar a los directores los incentivos adecuados para que recurran a esos procedimientos. Con frecuencia, son los acreedores quienes utilizan esas opciones o inician un procedimiento oficial de insolvencia debido a que los directores de las empresas no actuaron en el momento oportuno.

7. [11] Varios ordenamientos jurídicos abordan la cuestión de alentar una pronta acción imponiendo al deudor la obligación de solicitar la apertura del procedimiento oficial de insolvencia dentro de un plazo especificado contado a partir del momento en que se produce la imposibilidad de pagar, para evitar que se realicen operaciones cuando la empresa ya es insolvente. Otros regímenes tratan la cuestión centrándose en las obligaciones del director en el período previo a la apertura del procedimiento de insolvencia, e imponiendo una responsabilidad por el daño causado por la continuación de las operaciones cuando estaba claro, o debería haberlo estado, que la insolvencia era inevitable. La justificación de estas disposiciones es crear incentivos adecuados para que se actúe cuanto antes recurriendo con prontitud a las negociaciones de reestructuración o a la reorganización, e impedir que los directores externalicen los costos de las dificultades financieras de la empresa y hagan recaer todos los riesgos de las operaciones ulteriores sobre los acreedores.

8. [12] La imposición de esas obligaciones ha sido objeto de un debate continuo. Quienes reconocen que este enfoque tiene sus ventajas⁵, señalan que las obligaciones pueden servir para alentar a los directores a actuar con prudencia y a adoptar medidas tempranas para poner freno al deterioro de la empresa con miras a proteger a los acreedores ya existentes, a fin de que no sufran pérdidas aún mayores, y a los acreedores futuros, para que no se vean involucrados en las dificultades financieras de la empresa. Dicho de otra manera, las obligaciones pueden también tener el efecto de controlar y disciplinar a los directores, disuadiéndolos de embarcarse en actuaciones excesivamente arriesgadas o de consentir pasivamente en que se adopten medidas excesivamente arriesgadas propuestas por otros directores, debido a las sanciones que conlleva el incumplimiento de las obligaciones. Una ventaja adicional podría ser que incentivan a los directores a recabar asesoramiento profesional competente cuando se vislumbran dificultades financieras.

9. [13] Los comentaristas que opinan que hay importantes desventajas citan los ejemplos siguientes. Una norma por la que se presume la mala gestión basándose solamente en el hecho de la dificultad financiera suele provocar la renuncia de directores que por lo demás son idóneos y competentes y se pierde la oportunidad de reorganizar la sociedad y devolverle la rentabilidad. Existe la posibilidad de que los directores que deseen evitar la responsabilidad cierren prematuramente un negocio viable que podría haber sobrevivido, en lugar de intentar encontrar una solución a las dificultades de la empresa. Sin embargo, unas disposiciones debidamente formuladas desalentarían un cierre demasiado apresurado de los negocios y alentarían a los directores a seguir operando cuando esta sea la forma más adecuada de reducir al mínimo las pérdidas para los acreedores y tienen más

⁵ Por ejemplo, *Directors in the Twilight Zone III* (2009), INSOL International, Overview, pág. 5.

probabilidades de lograr un equilibrio entre los derechos y las expectativas legítimas de todas las partes interesadas, distinguiendo los casos de mala conducta de los casos en los que intervienen las condiciones del mercado u otros factores exógenos. Otra desventaja que se ha citado es que las obligaciones pueden ser vistas como un menoscabo de la situación jurídica asociada con la responsabilidad limitada, aunque cabe argüir que la responsabilidad limitada debería considerarse un privilegio y que los tribunales han sido conscientes de las posibilidades de abuso de la responsabilidad limitada cuando va en detrimento de los acreedores. Puede considerarse también que esas obligaciones debilitan los incentivos para la empresa, debido a que un riesgo demasiado elevado puede desalentar a los directores. Unas disposiciones debidamente formuladas, sin embargo, deberían centrarse no tanto en las causas de las dificultades como en las acciones (u omisiones) de los directores una vez que se han presentado esas dificultades. Ejemplos tomados de Estados que incluyen esas obligaciones en sus legislaciones indican que solo los directores más claramente irresponsables terminan siendo sancionados.

10. [14] Se dice asimismo que esas obligaciones pueden acrecentar la imprevisibilidad, ya que la responsabilidad depende de las circunstancias concretas de cada caso y también de las actitudes futuras de los tribunales. Se ha sugerido que muchos tribunales carecen de la experiencia necesaria para examinar el comportamiento comercial después de los hechos y pueden inclinarse por poner en tela de juicio las decisiones tomadas por los directores en el período en cuestión. Sin embargo, en los Estados que tienen experiencia en la aplicación de esas obligaciones, los tribunales han tendido a respetar las acciones de los directores, especialmente si han actuado basándose en un asesoramiento independiente. Otro inconveniente que se ha mencionado es el aumento del riesgo de responsabilidades imprevistas para los bancos y para otros que puedan ser considerados como directores en razón de su participación en la empresa, especialmente en el momento de la insolvencia. Es conveniente que la legislación sobre la materia brinde la debida protección a esas partes cuando actúen de buena fe, de forma autónoma respecto del deudor y de manera comercialmente adecuada⁶. Se sostiene también que la imposición de esas obligaciones compensa en exceso a los acreedores que pueden protegerse por medio de sus contratos, con lo que la regulación se vuelve superflua. Sin embargo, ese criterio presupone, por ejemplo, que todos los acreedores tengan un contrato con el deudor, que sean capaces de negociar las debidas salvaguardias para cubrir una amplia gama de imprevistos y que tengan los recursos, la voluntad y la capacidad de seguir de cerca los asuntos de la empresa. No todos los acreedores están en esta situación.

11. [15] Las obligaciones y responsabilidades de los directores se especifican en diferentes normas legales en los distintos Estados, tales como el derecho de sociedades, el derecho civil, el derecho penal y el régimen de la insolvencia y, en algunos casos, pueden figurar en más de una de esas normas legales o estar divididas entre varias de ellas. En los sistemas de derecho anglosajón, las obligaciones pueden aplicarse en virtud del *common law* o de conformidad con la legislación pertinente. Además, existen diferentes opiniones sobre si las obligaciones y responsabilidades de los directores corresponden en realidad al ámbito del régimen de la insolvencia o al del derecho de sociedades. Estas opiniones giran en torno al hecho de que, si la empresa es solvente, rige normalmente el

⁶ Véase el párr. 27 [21].

derecho de sociedades, mientras que si la empresa es objeto de un procedimiento de insolvencia, rige el régimen de la insolvencia (si bien existen ejemplos en los que no se puede establecer una distinción tan clara)⁷. El período anterior a la apertura de un procedimiento de insolvencia, cuando un deudor puede ser técnicamente insolvente, plantea problemas que en la actualidad pueden no encontrar una respuesta adecuada ni en el derecho de sociedades ni en el régimen de la insolvencia. Sin embargo, la imposición de obligaciones aplicables retroactivamente después de la apertura de un procedimiento de insolvencia puede conducir a un traslape de las obligaciones estipuladas en diferentes regímenes, y conviene conciliar esas obligaciones para asegurar la transparencia y la claridad y evitar posibles conflictos.

12. [16] No solo varían los regímenes en que se estipulan las obligaciones, sino también las obligaciones mismas: como se ha señalado más arriba, las que se aplican antes de la apertura de un procedimiento de insolvencia suelen ser distintas de las que se aplican después de ella (véase la segunda parte, capítulo III, párrafos 22 a 33). Las normas que deben observar los directores al desempeñar sus funciones también suelen variar según la naturaleza y el tipo de entidad empresarial de que se trate, por ejemplo, una empresa pública en contraposición a una sociedad anónima, una empresa con pocos accionistas o privada o una empresa familiar, y según la jurisdicción en que la empresa opere y pueden depender también de si el director es un externo independiente o un director interno.

13. [17] La aplicación de las leyes que regulan las obligaciones y responsabilidades de los directores está estrechamente relacionada con otras normas y disposiciones legales sobre la gobernanza de las empresas, e interactúa con ellas. En algunos Estados, esas leyes constituyen una parte fundamental de los marcos normativos, como los que protegen a los depositantes en instituciones financieras, facilitan la recaudación de ingresos fiscales o reglamentan la prelación de determinadas categorías de acreedores respecto de otros (como los empleados), además de los correspondientes marcos jurídicos, empresariales y culturales a nivel local.

14. [18] Una reglamentación eficaz en este ámbito debería tratar de equilibrar los objetivos e intereses, a menudo contrapuestos, de las distintas partes interesadas: salvaguardar la libertad de los directores de cumplir sus obligaciones y actuar debidamente conforme a su criterio, alentar un comportamiento responsable, desalentar las conductas indebidas y la adopción de medidas excesivamente arriesgadas, promover la actividad empresarial y alentar, desde un principio, la refinanciación o reorganización de las empresas con dificultades financieras o al borde de la insolvencia. Esa reglamentación podría reforzar la confianza de los acreedores y su disposición a hacer negocios con las empresas, alentar la participación de directores más experimentados, que de otra forma podrían ser reacios a participar debido a los riesgos que supondría una quiebra, y promover la buena gobernanza empresarial, generando una situación jurídica más previsible para los directores y limitando los riesgos de que los profesionales de la insolvencia entablen demandas en su contra una vez iniciado el procedimiento de insolvencia. Las directrices poco prácticas, confusas, anticuadas e incoherentes sobre las obligaciones de los responsables de adoptar decisiones con respecto a la gestión de

⁷ Reconociendo este problema, las recomendaciones de esta [parte] adoptan el criterio flexible de referirse a “la ley relativa a la insolvencia”.

una empresa al borde de la insolvencia pueden menoscabar las ventajas que un régimen de la insolvencia eficaz y eficiente pretende establecer y agravar la dificultad financiera que pretenden solucionar.

15. [19] El propósito de esta [parte] es determinar los principios básicos que deben plasmarse en el régimen de la insolvencia en lo que respecta a las obligaciones de los directores cuando la empresa se encuentra ante una insolvencia inminente o la insolvencia se vuelve inevitable. Estos principios pueden servir de puntos de referencia y ser usados por los responsables de la formulación de políticas al examinar y elaborar los marcos jurídicos y reguladores adecuados. Aunque se reconoce la conveniencia de alcanzar los objetivos del régimen de la insolvencia (enunciados en la primera parte, capítulo I, párrafos 1 a 14, y en la recomendación 1) mediante una acción temprana y un comportamiento adecuado de los directores, está claro también que unas normas excesivamente draconianas pueden entrañar escollos y amenazas para el espíritu empresarial. Esta [parte] no trata de las obligaciones de los directores que puedan aplicarse en virtud del derecho penal, el derecho de sociedades o el derecho de la responsabilidad civil, sino que se concentra solamente en aquellas que podrían incluirse en el régimen correspondiente y serían ejecutables una vez entablado un procedimiento de insolvencia.

II. Elementos de las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia

A. La naturaleza de las obligaciones

16. [28] Aunque el motivo de fondo para considerar las obligaciones de los directores en la proximidad de la insolvencia puede ser parecido en diferentes ordenamientos jurídicos, se adoptan enfoques distintos para formular esas obligaciones y determinar el criterio que se ha de cumplir. Sin embargo, en general los regímenes suelen centrarse en dos aspectos: en primer lugar, la imposición de responsabilidad civil a los directores por haber causado la insolvencia o por no haber adoptado las medidas adecuadas en la proximidad de la insolvencia (lo que en algunos regímenes puede incluir iniciar un procedimiento de insolvencia en virtud de la obligación de hacerlo con arreglo a la legislación nacional; véase el párr. 17 [29]) y, en segundo lugar, una vez que se ha iniciado el procedimiento de insolvencia, la anulación de las medidas tomadas por los directores, entre ellas las operaciones que se hayan podido realizar, en la proximidad de una insolvencia.

1. Obligación de iniciar un procedimiento de insolvencia

17. [29] Como se ha indicado más arriba, algunos regímenes nacionales imponen a los directores la obligación de solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia, que incluiría la reorganización o la liquidación, dentro de un plazo especificado, por lo general bastante corto, por ejemplo de tres semanas, contado a partir de la fecha en que la empresa pasó a ser técnicamente insolvente. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear una responsabilidad personal, total o parcial, por las pérdidas resultantes que afecten a la empresa o a sus acreedores y, en algunos casos, una responsabilidad penal, si la empresa sigue

operando. Esta obligación se examina con mayor detalle en la segunda parte, capítulo I, párrafos 35 y 36.

2. Responsabilidad civil

18. [30] La responsabilidad civil que recae en un director en la proximidad de la insolvencia se basa normalmente en la responsabilidad por haber causado la insolvencia o no haber adoptado las medidas adecuadas para vigilar la situación financiera de la empresa, evitar o mitigar las dificultades financieras, reducir al mínimo las posibles pérdidas para los acreedores y evitar la insolvencia. Los directores pueden incurrir en responsabilidad cuando efectúan operaciones con fines que no sean el de atenuar la dificultad financiera y preservar el valor de la empresa (por ejemplo, operaciones de alto riesgo o actos de disposición de bienes de la masa de la empresa que se puedan traducir en un aumento significativo de la exposición de los acreedores, sin que esté justificado). También pueden incurrir en responsabilidad si sabían que la insolvencia era inevitable o que la empresa no podría cumplir sus obligaciones a su vencimiento y sin embargo siguieron realizando actividades comerciales que entrañaban, por ejemplo, la obtención de bienes y servicios a crédito, sin ninguna posibilidad de reembolsar esos créditos y sin informar de la situación financiera de la empresa a esos acreedores. En algunos regímenes, los directores pueden incurrir en responsabilidad cuando no cumplen diversas obligaciones, por ejemplo notificar la imposibilidad de efectuar ciertos pagos, como los impuestos o las primas de la seguridad social, o presentar una declaración oficial de insolvencia.

19. [31] Salvo en aquellos regímenes en que los directores tienen la obligación de informar o de hacer declaraciones oficiales, por lo general se espera de los directores que en las circunstancias arriba descritas actúen de manera razonable y adopten medidas suficientes y adecuadas para controlar la situación, a fin de mantenerse informados y poder así intervenir para reducir al mínimo las pérdidas de los acreedores y la empresa (incluidos sus accionistas) y, eviten todo acto que pudiera agravar la situación y tomen las medidas apropiadas para evitar que la empresa caiga en la insolvencia.

20. [32] Las medidas suficientes y adecuadas pueden comprender, según las circunstancias del caso, la totalidad o una parte de lo siguiente:

a) Los directores pueden asegurarse de que las cuentas se lleven debidamente y estén actualizadas. De no ser así, deben velar por que la situación se corrija;

b) Los directores pueden obtener información exacta, pertinente y oportuna, en particular informándose independientemente (en lugar de basarse únicamente en el asesoramiento de la dirección) de la situación financiera de la empresa, el alcance de la presión de los acreedores y las medidas judiciales o de recuperación que hayan adoptado, o las controversias con los acreedores. Puede que los directores deban dedicar más tiempo y atención a los asuntos de la empresa en ese momento del que necesitarían dedicarle cuando la sociedad es próspera;

c) Pueden convocarse reuniones regulares del consejo de administración para vigilar la situación, levantando actas detalladas de las decisiones comerciales (incluidas las expresiones de disenso) y las razones de ellas, incluidas, cuando sea el caso, las razones por las que se permite a la empresa seguir operando y por las que

se considera que existe una posibilidad razonable de evitar la liquidación. Las medidas adoptadas pueden entrañar una continuación de las operaciones, ya que en algunos casos puede ser adecuado hacerlo incluso después de haber llegado a la conclusión de que la liquidación es inevitable, por ejemplo si la empresa posee bienes por los que se conseguirá un valor mucho mayor si se trata de una venta como negocio en marcha. Cuando para continuar las operaciones se requieran préstamos adicionales o nuevos (si el régimen de la insolvencia lo permite), la justificación para obtenerlos e incurrir así en nuevos pasivos deberá constar por escrito, para poseer una documentación que justifique la acción de los directores en caso de que se necesite posteriormente;

d) Puede solicitarse el asesoramiento o la asistencia de especialistas, con inclusión de especialistas en la insolvencia. Si bien el asesoramiento jurídico puede ser importante para los directores en este momento, las cuestiones fundamentales relacionadas con la situación financiera de la empresa suelen ser de carácter comercial más que jurídico. Conviene que los directores examinen la situación financiera de la empresa y determinen por sí mismos los resultados posibles, pero también que recaben asesoramiento para asegurarse de que las decisiones que adopten resistan un examen objetivo e independiente. [En este caso, los directores, ya sea colectivamente, como directores internos o como directores independientes, pueden contratar a contables, expertos en reestructuración o abogados independientes que asesoren autónomamente sobre las opciones que tiene el consejo de administración para determinar la viabilidad de las propuestas formuladas por los directivos];

e) Pueden celebrarse conversaciones con los auditores en una fase temprana y, de ser necesario, puede prepararse una auditoría externa;

f) Los directores pueden estudiar la estructura y las funciones de la empresa con vistas a analizar la viabilidad y reducir los gastos. También puede examinarse la posibilidad de celebrar negociaciones de reestructuración o de iniciar una reorganización y preparar un informe al respecto. [Los directores pueden examinar también la capacidad de la dirección actual, con miras a determinar si debe ser mantenida o sustituida];

g) Los directores pueden modificar las prácticas de gestión para centrarse en una serie de partes interesadas, que podrían incluir a los acreedores, los empleados, los proveedores, los clientes, los gobiernos, los accionistas y, en algunas circunstancias, el entorno, a fin de determinar las medidas que conviene adoptar. Cuando la insolvencia se vuelve inminente o inevitable, el hecho de tener también en cuenta los intereses de los acreedores en lugar de concentrarse en maximizar el valor para los accionistas impulsa a los directores a reducir al mínimo el daño para los acreedores (que serán las principales partes interesadas una vez que se abra el procedimiento de insolvencia), que pueda ser consecuencia de una conducta excesivamente arriesgada, imprudente o gravemente negligente. Celebrar reuniones con los grupos de acreedores pertinentes puede ser un mecanismo apropiado para determinar esos intereses;

h) Los directores pueden velar por que los activos de la empresa estén protegidos⁸ y que esta no adopte medidas que lleven a la pérdida de empleados clave ni realice operaciones del tipo mencionado en la recomendación 87 que puedan evitarse ulteriormente, como la venta de bienes a un valor demasiado bajo. No todos los pagos u operaciones efectuados en este período son necesariamente sospechosos; los pagos para asegurar el mantenimiento de los suministros o servicios importantes, por ejemplo, pueden no constituir una preferencia si el objetivo era la supervivencia de la empresa. Conviene dejar clara constancia por escrito de las razones por las que se efectuó el pago, para el caso de que la operación se cuestione posteriormente. Los directores con un gran paquete accionario o que representen a importantes accionistas no se pueden considerar desinteresados ni imparciales, y en el período cercano a la insolvencia deberían tener particular cuidado cuando voten sobre operaciones;

i) Puede convocarse una asamblea de accionistas, en el mejor interés de la empresa y sin dilación indebida, si del balance se desprende que una proporción estipulada del capital accionario se ha menoscabado (esto se aplica por lo general cuando el régimen incluye requisitos de mantenimiento de capital);

[j) Puede examinarse la composición del consejo de administración para determinar si incluye un número adecuado de directores independientes.]

3. Anulación de operaciones

21. [33] Las recomendaciones 87 a 99 tratan de la necesidad de evitar las operaciones de venta por un valor demasiado bajo, las operaciones que confieran una preferencia, y aquellas que tengan por objeto impedir, obstaculizar o demorar el pago a los acreedores (véase la segunda parte, capítulo II, párrafos 170 a 185). Esas recomendaciones se aplicarían a la anulación de operaciones concertadas por la empresa en la proximidad de la insolvencia. [Que una operación sea anulable no basta por sí solo para imponer una responsabilidad personal a los directores.]

21A. [33] [Sin embargo, determinadas operaciones anulables pueden tener también otras consecuencias.] Algunos regímenes consideran ilícitas determinadas actuaciones de los directores en virtud, por ejemplo, de las disposiciones sobre comercio ilícito o fraudulento, o por ser actos que empeoraron la situación económica de la empresa o la llevaron a la insolvencia, como el hecho de contraer nuevos préstamos o proporcionar nuevas garantías sin una justificación comercial suficiente. Además de la anulación de esas operaciones, en algunos regímenes los directores pueden incurrir en responsabilidad personal por permitir que la empresa concertara esas operaciones [fraudulentas o inapropiadas de otro modo]. Con arreglo a esas disposiciones, la responsabilidad se aplicará por lo general solo a los directores que hayan estado de acuerdo con la operación; aquellos que hayan disentido de forma expresa y cuyo disenso se haya hecho constar debidamente tienen probabilidades de evitar la responsabilidad.

⁸ No todos los activos requerirán necesariamente protección en todas las circunstancias. Un ejemplo de los tipos de activos que tal vez no necesiten protección en todas las circunstancias pueden ser los que estén asegurados por un valor inferior al de su garantía, sean gravosos, carentes de valor o difíciles de convertir en efectivo (esto se examina más detenidamente en la segunda parte, capítulo II, párr. 88).

Recomendaciones 1 y 2

Finalidad de las disposiciones legislativas

Las disposiciones relativas a las obligaciones de los responsables de adoptar decisiones acerca de la gestión de una empresa que nacen cuando la insolvencia es inminente o inevitable tienen por finalidad:

- a) Proteger los intereses legítimos de los acreedores y demás interesados;
- b) Velar por que los responsables de adoptar decisiones acerca de la gestión de una empresa estén enterados de sus funciones y responsabilidades en esas circunstancias;
- c) Proveer recursos apropiados en caso de incumplimiento de esas obligaciones, que podrán hacerse efectivos una vez comenzado el procedimiento de insolvencia.

Los párrafos a) a c) se aplicarán de forma que:

- a) No resulten en perjuicio de la reorganización satisfactoria de la empresa;
- b) No desalienten la participación en la gestión de empresas, especialmente las que experimentan dificultades financieras;
- c) No impidan la aplicación de un discernimiento comercial razonable o que se asuma un riesgo comercial razonable.

Contenido de las disposiciones legislativas

Las obligaciones

1. La ley relativa a la insolvencia debería especificar que, a partir del momento mencionado en la recomendación 3, las personas citadas en [de acuerdo con] la recomendación 4 tendrán la obligación de tener debidamente en cuenta los intereses de los acreedores y demás interesados, así como la obligación de adoptar medidas razonables para:

- a) evitar la insolvencia; y
- b) cuando la insolvencia sea inevitable, reducir al mínimo su alcance.

2. [1] A los efectos de la recomendación 1, entre las medidas razonables podrán figurar las siguientes:

- a) Evaluar la situación financiera de la empresa y asegurar que las cuentas se lleven debidamente y estén actualizadas; informarse de manera independiente acerca de la situación financiera en que se encuentra la empresa y su situación general; celebrar reuniones periódicas del consejo de administración para vigilar la situación; obtener asesoramiento profesional, incluso asesoramiento jurídico o relativo a la insolvencia; mantener conversaciones con los auditores; convocar una asamblea de accionistas; modificar las prácticas de gestión para tener en cuenta los intereses de los acreedores y otras partes interesadas; proteger los activos de la empresa para obtener el máximo valor y evitar la pérdida de activos fundamentales; estudiar la estructura y las funciones de la empresa para examinar la viabilidad y reducir los gastos; no permitir que la empresa se comprometa a concertar determinados tipos de operaciones que podrían ser anuladas a no ser que ello se

justifique debidamente desde el punto de vista empresarial; seguir comerciando en las circunstancias en que resulte apropiado hacerlo, para obtener el máximo valor del negocio en marcha; mantener negociaciones con los acreedores o iniciar otros procedimientos oficiosos, como negociaciones para una reestructuración de carácter voluntario⁹;

b) Iniciar un procedimiento oficial de reorganización o liquidación cuando sea apropiado hacerlo o cuando lo exija la legislación nacional.

B. Cuándo nacen las obligaciones: el período cercano a la insolvencia

22. [24] El momento en que podrían nacer las obligaciones examinadas más arriba se ha denominado de diversas formas, como la “zona gris”, la “zona de insolvencia” o la “proximidad de la insolvencia”. Aunque el concepto puede ser impreciso, pretende describir un período en que existe tal deterioro de la estabilidad financiera de la empresa que la insolvencia se ha vuelto inminente (vale decir, cuando la empresa deja de estar, en general, en condiciones de pagar sus deudas a su vencimiento (recomendación 15 a) de la Guía Legislativa)) o es inevitable. Determinar con exactitud el momento en que nacen esas obligaciones es una cuestión fundamental para los directores que tratan de adoptar decisiones en forma oportuna y compatible con esas obligaciones. Además, sin un punto de referencia claro sería difícil para los directores predecir con exactitud qué momento [del período anterior al comienzo del procedimiento de insolvencia] habría de tener en cuenta el tribunal al entender en una demanda por incumplimiento de esas obligaciones.

23. [25] Hay diversas posibilidades para determinar el momento en que pueden nacer las obligaciones de los directores en el período anterior al comienzo del procedimiento de insolvencia y se adoptan distintos criterios. Una posibilidad podría ser el momento en que se presenta una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia, y esta podría considerarse la opción que proporciona la mayor certidumbre. Sin embargo, si el régimen de la insolvencia prevé la apertura automática de un procedimiento después de una solicitud, o si el plazo entre la solicitud y la apertura es muy corto (véase la recomendación 18), esta opción surtirá escaso efecto por lo que respecta a alentar a los directores a actuar con prontitud.

24. [26] Otra posibilidad se centra en las obligaciones que nacen cuando una empresa es insolvente de hecho, lo que, en algunos regímenes, puede ocurrir bastante antes de que se presente una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia. Adoptando el enfoque general de la Guía Legislativa, cabría decir que la insolvencia ha ocurrido de hecho a partir del momento en que una empresa no puede pagar sus deudas en la fecha de su vencimiento, o cuando el pasivo de una empresa es superior al valor de su patrimonio (recomendación 15). Otra posibilidad es cuando la insolvencia es inminente, es decir, cuando la empresa deja de estar en general en condiciones de pagar sus deudas a su vencimiento (recomendación 15 a)). Estos criterios, sin embargo, se utilizan cada vez más en los regímenes de la insolvencia como criterios de apertura, y en algunos Estados constituyen la base para imponer a los directores la obligación de solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia en un plazo especificado, habitualmente bastante

⁹ Véase Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia, primera parte, capítulo II, párrs. 2 a 18.

corto, después de que la empresa haya pasado a ser insolvente. En consecuencia, también es improbable que esos criterios animen a adoptar las medidas apropiadas lo suficientemente pronto.

25. [27] Un criterio algo diferente se basa en un examen del conocimiento de la situación que el director tenía en un momento anterior a la apertura del procedimiento de insolvencia cuando, por ejemplo, sabía, o debería haber sabido, que la empresa era insolvente o que la insolvencia era inminente y que no había perspectivas razonables de que la empresa pudiese evitar tener que abrir un procedimiento de insolvencia o que la continuidad de la empresa estaba amenazada. [El fundamento de este criterio es que sea aplicable a los directores que administren de un modo imprudente una empresa que esté atravesando dificultades financieras y proporcionar incentivos para que se adopten las medidas apropiadas en el mejor momento.] Si bien una preocupación que suscita este tipo de criterio es la dificultad de determinar con certeza el momento exacto en que pudiera considerarse que el director tenía ese conocimiento, si las cuentas de la empresa se han llevado adecuadamente y son exactas, el director debería poder entender cuándo se encuentra en dificultades la empresa y cuándo podría correr el riesgo de cumplir los criterios para la insolvencia. O bien puede suponerse que el director conocía la información que se habría revelado si la empresa hubiese cumplido su obligación de llevar debidamente los libros de contabilidad y preparar las cuentas anuales. Esencialmente esto requiere evaluar la actuación del director en función del conocimiento que un director razonable habría o debería haber tenido en las circunstancias del caso. Este criterio requeriría un análisis más detenido de las circunstancias y el contexto, lo que incluiría, por ejemplo, un examen de los libros de la empresa y de su situación financiera completa. Podría entrañar un estudio de las corrientes de ingresos, de las deudas contraídas y de los imprevistos, incluida la capacidad de recaudar fondos. En general, la prueba de una falta temporal de liquidez no sería suficiente.

Recomendación 3

Finalidad de las disposiciones legislativas

[La finalidad de las disposiciones relativas al momento en que surgen las obligaciones es determinar en qué momento del período previo a la apertura del procedimiento de insolvencia deberían nacer las obligaciones.]

Contenido de las disposiciones legislativas

¿Cuándo nacen las obligaciones?

3. [2] La ley relativa a la insolvencia debería especificar que las obligaciones mencionadas en la recomendación 1 nacen en el momento en que la persona mencionada en [de acuerdo con] la recomendación 4 supo, o debería razonablemente haber sabido, que la insolvencia era inminente o inevitable.

C. Determinación de las partes en las que recaen las obligaciones

26. [20] En la mayoría de los Estados, una serie de personas diferentes relacionadas con la empresa tienen obligaciones respecto de la gestión y supervisión de las operaciones. Puede tratarse de los propietarios de la empresa, de directores

designados oficialmente (que pueden ser externos independientes o ejecutivos o gerentes de la empresa que pueden desempeñar el cargo de directores ejecutivos, denominados “directores internos”) y de personas y entidades no designadas, incluidos terceros que actúen en calidad de directores *de facto*¹⁰ o virtuales¹¹, así como personas en las que los directores hayan delegado las facultades o los deberes de un director¹².

27. [21] Una definición amplia puede incluir también a los asesores especiales y, en algunas circunstancias, a los bancos y otros prestamistas, cuando estén asesorando a una empresa sobre cómo solucionar sus dificultades financieras. En algunos casos, ese “asesoramiento” puede consistir en determinar el curso de acción exacto que debe adoptar la empresa y en imponer la adopción de un determinado curso de acción como condición para otorgar un crédito. No obstante, siempre que los directores de la empresa conserven la discreción de rechazar ese curso de acción, aun cuando en realidad pueda considerarse que no tienen más alternativa que aceptarlo porque de lo contrario se enfrentarían a una liquidación, y a condición de

¹⁰ En general, se considera que es un director *de facto* una persona que desempeña funciones directivas, pero que no ha sido nombrada oficialmente para ocupar ese cargo o cuyo nombramiento adolece de algún defecto técnico. Puede considerarse que una persona es un director *de facto*, independientemente del título oficial que se le haya asignado, si desempeña las funciones de ese cargo. Puede ser cualquier persona que en algún momento participe en la constitución, promoción o gestión de la empresa. En las pequeñas empresas de propiedad familiar puede ser un familiar, un antiguo director, un consultor e incluso un empleado de categoría superior. Normalmente, para que alguien sea considerado director *de facto* se precisará algo más que su mera participación en la gestión de la empresa, y su condición de tal podrá determinarse en función de que realice una serie de actos, como firmar cheques, firmar la correspondencia de la empresa como “director”, permitir que los clientes, acreedores, proveedores y empleados lo perciban como un director o un “responsable de adoptar decisiones”, y tomar decisiones financieras sobre el futuro de la empresa con los banqueros y contadores de la empresa.

¹¹ Un director virtual puede ser una persona no designada oficialmente como director, pero cuyas órdenes o indicaciones suelen determinar la conducta del personal directivo de la empresa. Por lo general, no se incluirá entre ellos a los asesores profesionales que actúen en calidad de tales. Para que alguien sea considerado un director virtual puede ser necesario que tenga la capacidad de influir en la totalidad o la mayoría del consejo de administración y de adoptar decisiones financieras y comerciales que vinculen a la empresa y, en algunos casos, que la empresa le haya cedido, totalmente o en parte, su autoridad de gestión. En el contexto de un grupo de empresas, un miembro del grupo puede ser director virtual de otro miembro perteneciente al grupo. Al examinar la conducta que puede dar lugar a que una persona sea considerada un director virtual, puede ser necesario tener en cuenta la frecuencia de esa conducta y si la influencia se ejerció efectivamente o no.

¹² Nota para el Grupo de Trabajo: el texto que figura a continuación puede incluirse en cualquier material que se prepare con respecto a los grupos de empresas o si no, suprimirse — Aunque algunas legislaciones disponen que un miembro de un grupo de empresas no puede ser nombrado director de otro miembro del grupo, con arreglo a una definición amplia del concepto de “director” un miembro del grupo sí puede ser considerado como un director de otros miembros del grupo. Ello ocurrirá normalmente cuando un miembro del grupo (o sus directores) desempeñe funciones relativas a la gestión y supervisión de otros miembros del grupo. Esto puede ser aplicable sobre todo en el contexto de los miembros controlados y principales de un grupo, cuando el miembro principal interfiere de manera sostenida y generalizada en la gestión del miembro controlado. Sin embargo, si un miembro controlado decide apoyar al miembro principal porque ello redundará en su propio interés y no como resultado de la interferencia del miembro principal, este último no podrá ser considerado como un director del miembro controlado.

que los asesores externos actúen autónomamente, de buena fe y de manera comercialmente adecuada, conviene que esos asesores no se incluyan en la categoría de las personas en las que recaen las obligaciones.

28. [22] No existe una definición universalmente aceptada de lo que constituye un “director”. Como criterio general, sin embargo, puede considerarse que una persona es un director si ha recibido el encargo de adoptar, o de hecho adopta o debería adoptar, decisiones fundamentales con respecto a la administración de la empresa, entre ellas funciones tales como las siguientes¹³: la determinación de la estrategia de la empresa, la política de riesgo, los presupuestos anuales y los planes de actividades; el control de los resultados obtenidos por la empresa; la supervisión de los principales desembolsos de capital; la vigilancia de las prácticas de gestión de la empresa; la selección y designación del director general y el apoyo a su desempeño; la garantía de la disponibilidad de recursos financieros suficientes; el tratamiento de los posibles conflictos de intereses; la garantía de la integridad de los sistemas de contabilidad y presentación de informes financieros; y la rendición de cuentas a las partes interesadas por el desempeño de la organización.

29. [22] Las obligaciones que se examinan *supra* recaerán en toda persona que sea director en el momento en que una empresa se enfrente a una insolvencia efectiva o inminente, y podrán afectar también a un director que posteriormente dimita (véase el párrafo 40 *infra*). Las obligaciones no se aplicarán a los directores que sean nombrados después de la apertura del procedimiento de insolvencia.

Recomendación 4 [3]

Finalidad de las disposiciones legislativas

[La finalidad de las disposiciones es determinar a quiénes deben aplicarse las obligaciones.]

Contenido de las disposiciones legislativas

Personas en quienes recaen las obligaciones

4. [3] La ley relativa a la insolvencia debería especificar la persona en quien recaen las obligaciones, que puede tratarse de un director designado oficialmente o cualquier otra persona que ejerza el control *de facto* y que ejerza las funciones de un director.

D. Responsabilidad

1. El criterio que ha de cumplirse

30. [34] En la normativa relativa a las obligaciones de los directores en la proximidad de la insolvencia, el comportamiento de los directores en ese período se juzga en función de una serie de criterios para determinar si han incumplido o no esas obligaciones. [24] Normalmente, esas obligaciones solo serían ejecutables una vez que se hubiera iniciado el procedimiento de insolvencia y como consecuencia de su apertura, y se aplicarían retroactivamente de la misma manera que las

¹³ Esos ejemplos se ofrecen a título informativo y no se enumeran en ningún orden de importancia.

disposiciones de anulación (véase el análisis que figura en la segunda parte, cap. II, párrs. 148 a 150 y 152).

31. [35] En algunos regímenes, la cuestión de determinar en qué momento un director o ejecutivo supo, o debería haber sabido, que la empresa era insolvente o que era probable que cayera en la insolvencia se resuelve basándose en los criterios del conocimiento general, la pericia y la experiencia que cabe esperar razonablemente de una persona que desempeñe las funciones que ese director cumple en relación con la empresa. Puede esperarse más de un director de una gran empresa con sistemas y procedimientos contables avanzados. Si la pericia y experiencia del director exceden de las necesarias para la función, el juicio se podrá formular con arreglo a la pericia y la experiencia poseídas, en lugar de las necesarias para la función. En cambio, es posible que una pericia y experiencia insuficientes para la función no sirvan de excusa a un director, que podría ser juzgado con arreglo a la pericia y experiencia necesarias para la función.

32. [36] Otro enfoque exige que hubiera motivos razonables para sospechar que la empresa era insolvente o que caería en la insolvencia en el momento de contraer la deuda o realizar la operación que dieron lugar a la insolvencia. Que haya motivos razonables para sospechar la insolvencia exigiría algo más que meras conjeturas, y el director debe tener una aprensión real de que la empresa es insolvente. Este es un umbral más bajo que el hecho de prever o saber que la empresa es insolvente. Con arreglo a este enfoque, el criterio es el de un director de competencia normal que es capaz de tener una comprensión básica de la situación financiera de la empresa, y la evaluación se hace teniendo en cuenta la información que ese director pudo tener y no la información que más tarde pudo darse a conocer. Los datos empíricos de los Estados en que rigen disposiciones de este tipo indican que, cuando se examina lo que ocurrió, a menudo cierto tiempo antes de que tenga lugar ese examen, los tribunales suelen tener un muy buen conocimiento de la posición en que se encontraron los directores, analizan cuidadosamente la situación a la que se vieron enfrentados y evalúan en su justo valor los problemas empresariales con que tropezaron. Los tribunales han sido reacios a cuestionar a los directores en sus operaciones comerciales, aduciendo que no es adecuado suponer que lo que de hecho ocurrió estaba destinado a ocurrir, o era necesariamente previsible en aquel momento.

33. [38] Algunos regímenes protegen a los directores, por ejemplo mediante la regla del criterio mercantil bien fundado, que establece una presunción de que los directores, por ejemplo, actuaron de buena fe y creían razonablemente que estaban sirviendo los mejores intereses de la empresa, no tenían un interés material personal, y se informaron debidamente. [A condición de que actuaran de buena fe, con la diligencia debida y dentro de sus competencias, los directores quedarán exentos de responsabilidad. Para acogerse a esa regla, los directores han de informarse con respecto a las cuestiones sobre las que se ha de decidir adquiriendo y estudiando la información que una persona sensata encontraría convincente en circunstancias similares y apoyándose en ella, y no tener ningún conflicto de intereses con respecto a esas cuestiones.]

34. [37] Otro enfoque se centra en la mala gestión. Los regímenes que adoptan este enfoque pueden exigir que haya un nexo causal entre el acto de mala gestión y las deudas dimanantes de él, o que la mala gestión haya sido una causa importante de la insolvencia de la empresa. Según este criterio, tiene que haber habido un error

de gestión imputable al director, sobre la base de lo que haría un director normalmente bien asesorado. Entre los ejemplos de comportamientos o actos que pueden dar lugar a responsabilidad con arreglo a esos regímenes figuran la imprudencia, la incompetencia, la falta de atención, la inacción, la realización de transacciones en condiciones que no sean de plena competencia o de carácter comercial y la concesión indebida de crédito por encima de los medios de la empresa, mientras que los errores por omisión más habituales han sido los de directores que han permitido que la empresa comerciara cuando ya era manifiestamente insolvente o que han emprendido proyectos por encima de la capacidad económica de la empresa y que no redundaban en su mejor interés. Otros ejemplos de mala gestión son los casos en que los directores no investigan suficientemente la solidez financiera de los socios comerciales u otros factores importantes antes de concertar contratos, en que los directores no facilitan información suficiente para que el consejo supervisor pueda ejercer la supervisión de los directivos, en que los directores descuidan la debida administración financiera de la empresa, en que no adoptan tampoco medidas preventivas contra riesgos claramente previsible, y en que la mala gestión del personal por los directores da lugar a malestar y huelgas. En algunos ordenamientos jurídicos que adoptan ese criterio, para determinar que hubo mala gestión no es necesario que el director haya intervenido activamente en la gestión de la empresa; la aquiescencia pasiva puede bastar.

2. El carácter de la responsabilidad

35. [32A] [Para determinar si un director concreto ha incumplido sus obligaciones es necesario examinar sus circunstancias personales. Una vez que se ha determinado el incumplimiento de las obligaciones con arreglo a los requisitos probatorios correspondientes, la responsabilidad puede ser atribuida de varios modos. Con arreglo a un enfoque, la responsabilidad será atribuida a cada director en proporción a su participación concreta en las decisiones o comportamientos examinados, exigiéndose el examen de esa participación en todas las circunstancias.]

36. [32A] [Varios otros regímenes establecen la regla general de que los directores responderán mancomunada y solidariamente por no cumplir esas obligaciones. Así puede ocurrir incluso aunque cada director no sea responsable del cumplimiento de todas las obligaciones correspondientes. Algunos de esos regímenes, no obstante, disponen que el tribunal puede decidir sin embargo la contribución de cada director tomando en consideración los hechos del caso, por ejemplo los diferentes niveles de culpabilidad. El tribunal puede por ejemplo ordenar que uno de los directores asuma el total de la responsabilidad (cuando, por ejemplo, a ese director se le hubieran asignado personalmente obligaciones concretas relacionadas con el perjuicio que se está examinando) u ordenar que un director contribuya en mayor medida cuando, por ejemplo, se haya determinado que la culpabilidad por el daño causado no es equitativa. En un régimen, solo se puede exigir responsabilidad mancomunada y solidaria a los directores si se demuestra que cometieron un fraude o una deshonestidad a sabiendas; en todos los demás casos, la responsabilidad es proporcional a la medida en que las actuaciones del director contribuyeron a las pérdidas de la sociedad. En otro régimen se adopta un enfoque ligeramente diferente en el que el tribunal determina si una persona juzgada responsable debe indemnizar a la empresa, en función de la gravedad de la culpa y la solidez del nexo causal, pero la cuantía de la indemnización no es necesariamente proporcional al nivel de

responsabilidad o de culpa. En algunos regímenes, la cuestión de si la responsabilidad es mancomunada o se atribuye específicamente a los directores responsables de la conducta en cuestión (lo que puede incluir la inacción o no haber velado por que otros directores cumplieren con sus propias obligaciones) depende del acto que origina la responsabilidad.]

Recomendaciones 5 y 6

Finalidad de las disposiciones legislativas

[La finalidad de las disposiciones sobre responsabilidad es:

a) proporcionar normas para las circunstancias en las que los actos de una persona sujeta a las obligaciones enunciadas en la recomendación 1 que tienen lugar antes de que se inicie el procedimiento de insolvencia pueden ser considerados perjudiciales y por consiguiente, un incumplimiento de esas obligaciones; y

b) determinar las consecuencias de ese incumplimiento.]

Contenido de las disposiciones legislativas

Responsabilidad

5. [4] La ley relativa a la insolvencia debería especificar que cuando los acreedores han sufrido pérdidas o perjuicios como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la recomendación 1, la persona imbuida de las obligaciones puede ser responsable.

6. [4] La ley relativa a la insolvencia debería estipular que la responsabilidad [por] [derivada del] incumplimiento de las obligaciones de la recomendación 1 está limitada a la medida de las pérdidas y los daños que ha causado el incumplimiento.

E. Ejecución de las obligaciones de los directores respecto a la apertura de un procedimiento de insolvencia

1. Defensas

37. [38] En algunos regímenes, cuando los directores tienen obligaciones en la proximidad de la insolvencia, pueden recurrir a determinadas defensas, como la regla del criterio mercantil bien fundado, para demostrar que se han comportado de forma razonable. Un enfoque algo diferente concede a los directores el beneficio de la duda, partiendo del supuesto de que los riesgos mercantiles son inevitables y son una parte inherente a la gestión. Como se señaló anteriormente, los tribunales son reacios a cuestionar a un director que ha cumplido sus obligaciones de diligencia debida y lealtad, o a adoptar decisiones de carácter retrospectivo. También puede darse el caso de que la regla del criterio mercantil bien fundado sirva de defensa en relación con algunas de las obligaciones especificadas por la ley, pero no con todas.

38. [39] En algunos regímenes, los directores tendrán que demostrar que adoptaron las medidas adecuadas para reducir al mínimo toda posible pérdida para los acreedores de la empresa una vez que llegaron a la conclusión de que la empresa tendría dificultades para evitar la liquidación. Si pueden demostrar que tomaron decisiones comerciales razonables y objetivas, basadas en información financiera

exacta y en un asesoramiento profesional adecuado, es probable que puedan utilizar esta defensa aun cuando esas decisiones hayan resultado ser comercialmente desacertadas.

39. [32B] Algunos regímenes disponen también que los directores adopten determinadas medidas de procedimiento u oficiales para evitar o reducir su responsabilidad por decisiones o actuaciones que posteriormente se cuestionen, como por ejemplo dejar constancia de su oposición en las actas de la reunión; entregar un escrito en que expresen su desacuerdo al secretario de la reunión antes de que esta se levante; o entregar o enviar su oposición por escrito inmediatamente después de levantada la reunión al domicilio social de la empresa o a otro organismo que disponga la legislación nacional. Se puede considerar que los directores que han estado ausentes en una reunión en que se adoptaron esas decisiones han prestado su consentimiento a menos que cumplan con el procedimiento establecido, como por ejemplo adoptar las medidas necesarias para dejar sentada su oposición dentro de determinados plazos después de conocida la decisión en cuestión.

40. [40] El hecho de que un director no tenga conocimiento de los asuntos de la empresa no podrá generalmente ser aducido como excusa para el incumplimiento de las obligaciones. Además, la dimisión del director en la proximidad de la insolvencia no lo eximirá necesariamente de responsabilidad, ya que, en algunos regímenes, puede exponerse a que se considere que la dimisión estuvo relacionada con la insolvencia, que era consciente, o debería haberlo sido, de la insolvencia inminente y que no adoptó medidas razonables para reducir al mínimo las pérdidas para los acreedores y mejorar la situación. Si un director expresó su disenso respecto de una decisión que posteriormente es objeto de examen, ese disenso tendrá normalmente que constar por escrito para que el director pueda aducirlo en su favor. Cuando un director está en desacuerdo con los demás directores sobre el curso de acción que se ha de seguir y, pese a adoptar medidas razonables para persuadir a sus colegas no consigue hacerlo, puede ser adecuado que el director dimita, a condición de que quede constancia de sus esfuerzos y de sus consejos.

41. [32C] Se puede disminuir la responsabilidad mediante un seguro específico, que puede ser pagado por la empresa a sus directores, o mediante el uso de resarcimientos. [Cuando hay un seguro, los límites principales normalmente son el fraude deliberado y la actuación en provecho propio, con lo que los directores tienen generalmente cubierto el incumplimiento de las obligaciones examinadas salvo que la cobertura del seguro sea inadecuada, como puede ocurrir en la insolvencia.] En determinadas legislaciones es posible, cuando se ha presentado una denuncia contra un director, negociar un acuerdo con el representante de la insolvencia; este es el criterio habitual en algunas jurisdicciones.

2. Recursos

42. [41] Se prevén diferentes recursos y combinaciones de recursos en el derecho civil para el caso de que un director incumpla sus obligaciones. Los recursos se centran en la indemnización por el incumplimiento de la obligación y por los daños y perjuicios causados, aunque la manera de calcular el importe varía. Los daños y perjuicios no suelen tener carácter punitivo. [Varios] [Muchos] regímenes prevén también la inhabilitación del director para actuar como tal o participar en la conducción y gestión de una empresa.

a) *Daños y perjuicios e indemnización*

43. [42] Cuando se considera a los directores responsables de acciones u omisiones en la proximidad de la insolvencia, el grado de responsabilidad varía. En algunos regímenes, los directores pueden ser responsables de las pérdidas o perjuicios sufridos por distintos acreedores y empleados y por la propia empresa, cuando la pérdida es resultado directo de sus acciones u omisiones. También pueden ser responsables de los pagos que den lugar a una reducción de la masa de la insolvencia o que se hayan traducido en una disminución de los bienes de la empresa. Algunos regímenes permiten que el tribunal ajuste el grado de responsabilidad para equipararlo a la naturaleza y gravedad de la mala gestión o de otro acto que dé lugar a la responsabilidad. Algunos regímenes prevén que un director pueda ser considerado responsable de la diferencia entre el valor de los bienes de la empresa en el momento en que debería haber cesado de comerciar y el momento en que realmente dejó de hacerlo. Otra formulación del mismo concepto es la diferencia entre la posición de los acreedores y de la empresa después del incumplimiento y su posición de no haber existido tal incumplimiento. Un enfoque algo diferente puede permitir recuperar de los directores la diferencia entre los bienes disponibles y la suma necesaria para que la empresa satisfaga sus deudas.

44. [43] Algunos regímenes que prevén la obligación de solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia o de celebrar una asamblea de accionistas cuando haya una pérdida de capital prevén también la indemnización.

45. [44] Cuando los directores son considerados responsables puede especificarse que la cantidad recuperada engrosará la masa de la insolvencia dado que la justificación principal para demandar a los directores es recuperar en forma de indemnización para la masa de la insolvencia parte del valor que se ha perdido por sus actos. Aprovechará así a todos los acreedores, no a algunos en concreto. En algunos regímenes se estipula que, si la sociedad tiene una hipoteca de empresa, indemnización que se obtenga irá en beneficio de los acreedores no garantizados. Cabe sostener en apoyo de ese enfoque que la indemnización no debería beneficiar a los acreedores garantizados, ya que la causa de la acción no surge hasta la apertura del procedimiento de insolvencia y, por lo tanto, no puede estar sujeta a una garantía real creada por la empresa antes de ese momento. Además, lo que se pretende obtener no es la recuperación de los bienes de la empresa, a diferencia de lo que ocurre en un procedimiento de anulación, sino una contribución de los directores para indemnizar los daños y perjuicios sufridos por los acreedores. Sin embargo, cuando el régimen de la insolvencia permita que los acreedores demanden a los directores (véase *infra*), estaría justificado sugerir que cualquier indemnización que se haya de pagar se destine, en primer lugar, a cubrir las costas incurridas por el acreedor o los acreedores que iniciaron el procedimiento.

46. [45] Además de los recursos arriba mencionados, las deudas u obligaciones que la empresa tenga para con los directores pueden aplazarse o subordinarse, y se puede exigir a los directores que rindan cuentas de todo bien de la empresa que hayan adquirido o del que se hayan apropiado y de todo beneficio que hayan obtenido por el incumplimiento de sus obligaciones.

b) Inhabilitación

47. [46] Una consecuencia prevista en [varios] [muchos] regímenes cuando se abre un procedimiento de insolvencia es la inhabilitación de los directores para desempeñar ese cargo o participar en la conducción y gestión de una empresa. Tal medida suele considerarse una salvaguardia destinada a apartar a esos directores de los puestos en que puedan causar más daños al seguir desempeñando funciones de gestión y dirección en la misma empresa o en otra. Uno de los regímenes permite la inhabilitación por un período de entre 2 y 15 años si se considera que la persona no es “apta” para actuar como director. Entre los factores que se tienen en cuenta en esa determinación figuran los siguientes: el incumplimiento de una obligación fiduciaria, la utilización indebida de fondos, la presentación de estados de cuenta financieros y no financieros engañosos, y el hecho de no llevar las cuentas de la manera debida y de no presentar informes. También pueden incluirse actos relacionados con la insolvencia de la empresa, como la responsabilidad de esa persona en el hecho de que la empresa entablara operaciones susceptibles de ser anuladas por motivos del tipo de los que figuran en la recomendación 87, o de que la empresa siguiera comerciando pese a que el director sabía, o debiera haber sabido, que era insolvente. Los diversos factores se suelen considerar de forma acumulativa al determinar la falta de aptitud en un caso concreto. En los ordenamientos jurídicos que prevén la inhabilitación, las personas que son declaradas no aptas han dado muestras en muchos casos, aunque no siempre, de falta de probidad comercial, negligencia grave o incompetencia grave.

48. [47] La inhabilitación puede decidirse junto con los demás recursos y sanciones arriba descritos, o bien de forma independiente, cuando la conducta general de una persona como director merezca tal sanción. [Cuando es posible la inhabilitación, las personas facultadas para solicitarla pueden estar limitadas a los organismos u oficiales especificados, el representante de la insolvencia y, en algunos casos, los acreedores.]

3. Partes que pueden entablar una acción

49. [48] Varios regímenes limitan el derecho a entablar acciones contra un director por el incumplimiento de las obligaciones examinadas más arriba en función de la naturaleza de la acción y la persona facultada para ejercerla. Pueden ser de aplicación consideraciones parecidas a las aplicables al ejercicio de las facultades de anulación, que se examinan en la recomendación 87 (véase la segunda parte, capítulo II, párrafos 192 a 195).

50. [49] De conformidad con una serie de regímenes, cuando ya se ha abierto el procedimiento de insolvencia, el representante de la insolvencia es el único que, tras haber examinado los actos de un director antes de la insolvencia, tiene derecho a proceder contra el director para obtener una indemnización en beneficio de los acreedores respecto de cualesquiera pérdidas causadas a la empresa. Las normas sobre el comercio ilícito, por ejemplo, pueden autorizar al representante de la insolvencia a demandar a los directores para que hagan aportaciones a la masa de la insolvencia cuando su comportamiento haya contribuido a la insolvencia de la empresa o constituya un acto de mala gestión. Algunos regímenes permiten también que la demanda sea interpuesta por el fiscal público o de oficio por el tribunal.

51. [49A] Si bien una importante razón de imponer obligaciones a los directores en el período cercano a la insolvencia es la protección de los intereses de los acreedores, no todos los ordenamientos jurídicos permiten a estos demandar a un director por incumplimiento de sus obligaciones. Algunos regímenes reconocen en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando el representante de la insolvencia no adopta ninguna medida, a los acreedores y a veces a los accionistas el derecho de interponer una acción subrogatoria (véase la segunda parte, capítulo II, párrs. 192 a 195). [Cuando el resarcimiento por daños y perjuicios corresponderá a la masa de la insolvencia en beneficio de los acreedores, los accionistas tendrán escasa motivación para entablar esa acción. Otros regímenes autorizan únicamente a los acreedores a demandar por determinados tipos de acciones u operaciones, como ejercicio indebido del cargo u operaciones de venta por un valor demasiado bajo.] En otros regímenes, cuando los acreedores no tienen un derecho independiente a interponer una acción, un acreedor solo puede actuar contra los directores con el consentimiento de la mayoría de los acreedores o del comité de acreedores, o bien los acreedores pueden solicitar a su representante, al comité o al tribunal que interponga esa acción.

52. [49B] Cuando se considere conveniente que la ley permita a los acreedores demandar a los directores puede marcarse una distinción entre los acreedores cuya deuda nació en el período cercano a la insolvencia como resultado directo de la conducta en examen y los acreedores cuya deuda fuera anterior a ese período. Los primeros, además del derecho de iniciar procedimientos en beneficio de la masa de la insolvencia, pueden tener el derecho personal de reclamar daños y perjuicios contra el director sobre la base de que la conducta en cuestión ocurrió en el período cercano a la insolvencia y exacerbó las dificultades financieras del deudor. En algunas legislaciones ese derecho individual queda limitado a los casos en que el mal comportamiento en cuestión fue dirigido a un acreedor determinado. De considerarse conveniente permitir que los acreedores interpongan acciones contra el director, las disposiciones del régimen de la insolvencia aplicables a la anulación pueden servir de modelo para el procedimiento que habría que seguir (véase la segunda parte, párrs. 192 a 195). Por ejemplo, la ley puede requerir el consentimiento previo del representante de la insolvencia para asegurar que este tenga conocimiento del propósito de los acreedores y la oportunidad de denegar su autorización, evitando así cualquier perjuicio que esa actuación pueda causar a la administración de la masa de la insolvencia.

53. [49C] Cuando para demandar a un director el acreedor debe contar con el consentimiento del representante de la insolvencia o de los acreedores, pero no lo haya obtenido o le haya sido denegado, la ley puede permitirle solicitar la aprobación del tribunal. El representante de la insolvencia debería tener derecho a ser escuchado en la correspondiente vista judicial para explicar por qué considera que no debería continuarse con las actuaciones. En esa vista el tribunal podría autorizar que se interponga la demanda o podría decidir que examinará el fondo del caso. Ese criterio puede reducir la posibilidad de que las diversas partes lleguen a un arreglo. En los casos en que se permite que los acreedores interpongan una demanda de anulación, algunas legislaciones estipulan que las costas de la demanda sean a cargo de los acreedores o admiten la imposición de sanciones a los acreedores para desalentar posibles abusos; ese mismo criterio se puede aplicar a las demandas de los acreedores contra los directores.

54. [50] En los regímenes que imponen a los directores la obligación de abrir un procedimiento de insolvencia, la propia sociedad, sus accionistas y acreedores pueden tener derecho a una indemnización por daños y perjuicios en caso de incumplimiento de esa obligación. Si los directores han efectuado pagos contraviniendo una moratoria que acompañe a la obligación de abrir un procedimiento de insolvencia, la propia empresa puede tener derecho a una indemnización. La empresa puede tener ese derecho también en los regímenes que imponen la obligación de celebrar una asamblea de accionistas cuando se produzca una pérdida de capital. Es conveniente que el régimen de la insolvencia garantice la coordinación de las demandas que puedan iniciar las diferentes partes

55. [Los litigios relacionados con las obligaciones de los directores de una empresa objeto de un procedimiento de insolvencia probablemente serán no solo costosos, sino también lentos y pueden hacer que se demore la conclusión del procedimiento de insolvencia conexo. Si bien esta cuestión rebasa el presente análisis, tal vez mereciera la pena examinarla para reducir los efectos de esos litigios sobre ese procedimiento.]

4. Financiación del procedimiento

56. [51] Una dificultad que podría surgir en las jurisdicciones en que el representante de la insolvencia esté autorizado a entablar una demanda por el incumplimiento de esas obligaciones es la relativa al pago de sus costas en el caso de que no prospere. La falta de financiación disponible se cita a menudo como una razón importante de que los casos de demanda por incumplimiento de esas obligaciones sean relativamente escasos. Si bien pueden facilitarse fondos de la masa de la insolvencia cuando existan bienes suficientes para hacerlo, como suele ocurrir con los procedimientos de anulación, los representantes de la insolvencia pueden no estar dispuestos a utilizar esos bienes para entablar una demanda si no hay una probabilidad muy elevada de que esta prospere (véase la segunda parte, capítulo II, párr. 196). Sin embargo, en muchos casos los fondos disponibles en la masa de la insolvencia no serán suficientes para demandar a un director, aunque sean muchas las posibilidades de éxito.

57. [51] Encontrar en esas circunstancias un criterio de financiación alternativo puede ofrecer, en determinadas condiciones, un medio efectivo para devolver a la masa los bienes perdidos por actos de los directores, corregir abusos, investigar conductas desleales y promover la buena gobernanza. [Se facilitaría la obtención de esa financiación alternativa incluyendo una autorización apropiada en los regímenes de la insolvencia de un modo muy parecido al que se dispone en la recomendación 95 con respecto a la financiación del procedimiento de anulación.] Puede cederse a un tercero, incluso a los acreedores, la facultad de entablar el procedimiento, o el producto previsto de este si prospera, a cambio de un importe o se puede recurrir a un prestamista para que provea los fondos. Cuando el demandante es una parte distinta del representante de la insolvencia el costo de comenzar esas actuaciones puede recuperarse de la indemnización que se pague. En algunas legislaciones las demandas contra los directores se pueden dirimir mediante negociaciones con los representantes de la insolvencia, evitando la necesidad de financiación. En algunas jurisdicciones esto no es frecuente, mientras que en otras constituye una práctica habitual, y los representantes de la insolvencia suelen “invitar” a los directores a que hagan contribuciones. Como cuestión adicional, sería

apropiado considerar también el tribunal en que se pueden entablar esas actuaciones; esta cuestión se ha examinado *supra*, en la segunda parte, capítulo I, párr. 19.

Recomendaciones 7 a 11

Finalidad de las disposiciones legislativas

[La finalidad de las disposiciones sobre la ejecución de las obligaciones es establecer los recursos apropiados contra el incumplimiento de las obligaciones y facilitar la interposición y la sustanciación de las demandas para obtener indemnización por ese incumplimiento.]

Contenido de las disposiciones legislativas

Elementos de la responsabilidad y excepciones

7. [5] La ley relativa a la insolvencia debería especificar los elementos que habrán de probarse a fin de establecer el incumplimiento de las obligaciones enunciadas en la recomendación 1, y que esta ha provocado una pérdida o daño a los acreedores; a qué parte corresponde la carga de esa prueba; y las posibles excepciones que podrán oponerse a una alegación de incumplimiento de las obligaciones. Una de las excepciones que se pueden oponer es que la persona imbuida de las obligaciones ha adoptado medidas razonables del tipo de las mencionadas en la recomendación 2.

Recursos

8. [6] La ley relativa a la insolvencia debería especificar que los recursos oponibles cuando el tribunal determine que existe responsabilidad por un incumplimiento de la obligación enunciada en la recomendación 1 deberían incluir el pago completo a la masa de la insolvencia de todo resarcimiento por daños y perjuicios fijado por el tribunal [como indemnización por ese incumplimiento]. La falta de pago de la totalidad de esos daños debería limitar el ejercicio de compensación de la persona imbuida de la obligación con respecto a toda deuda que la empresa tenga con esa persona mientras no se haya efectuado el pago en su totalidad.

Sustanciación de la demanda por incumplimiento de la obligación

9. [7] La ley relativa a la insolvencia debería especificar que la causa de la acción por la pérdida o perjuicio sufrido como resultado del incumplimiento de las obligaciones enunciadas en la recomendación 1 corresponde a la masa de la insolvencia y el representante de la insolvencia es el principal responsable de interponer una demanda por incumplimiento de dichas obligaciones. La ley relativa a la insolvencia podrá también permitir a un acreedor o a cualquier otra parte interesada interponer esa demanda con el consentimiento del representante de la insolvencia. En caso de haberse denegado ese consentimiento, el acreedor o una otra parte interesada podrán solicitar autorización judicial para interponer dicha demanda.

Financiación de las demandas por incumplimiento de la obligación

10. [8] La ley relativa a la insolvencia debería especificar que las costas de la demanda contra la persona imbuida de las obligaciones se abonarán como gastos de administración de la masa.

11. [9] La ley relativa a la insolvencia podrá prever otras formas de regular la sustanciación y financiación de esas demandas.

Medidas adicionales

[12. [10] Para desalentar todo comportamiento que pueda dar lugar a la responsabilidad según lo dispuesto en la recomendación 5, la ley relativa a la insolvencia podrá incluir otros recursos¹⁴ además del pago [de un resarcimiento] [por daños y perjuicios] previsto en la recomendación 8.]

[¹⁴ Los recursos adicionales de que se podrá disponer dependerán de los tipos de recursos que haya disponibles en una determinada jurisdicción y de lo que, además del pago del resarcimiento, resulte proporcional al comportamiento en cuestión y apropiado en las circunstancias del caso concreto. Se examinan ejemplos de esos recursos en los párrafos --- [del comentario].]

I. Nota de la Secretaría sobre el centro de los principales intereses en el contexto de los grupos de empresas, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43º período de sesiones

(A/CN.9/WG.V/WP.114)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Antecedentes	1-2
II. Resumen de las deliberaciones anteriores del Grupo de Trabajo	3-13
III. Novedades en el trato otorgable a los grupos de empresas en situaciones de insolvencia	14-16
IV. Próximas medidas	17

I. Antecedentes

1. En su período de sesiones anterior, celebrado en noviembre de 2012, el Grupo de Trabajo opinó que era necesario examinar la cuestión del centro de los principales intereses en relación con los grupos de empresas, porque la mayor parte de la actividad comercial se realizaba actualmente por medio de esos grupos; que el alcance de su mandato con respecto al centro de los principales intereses aprobado inicialmente abarcaba esa cuestión en el contexto de los grupos de empresas, y que ese tema debería examinarse después de que se terminaran de introducir las modificaciones propuestas de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza (A/CN.9/763, párrs. 13 y 14).

2. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar que el alcance de su mandato con respecto al centro de los principales intereses aprobado inicialmente se refería también a la posibilidad de “elaborar una ley modelo o disposiciones modelo sobre el régimen de la insolvencia en que se regularan determinadas cuestiones del derecho internacional de la insolvencia, como las relativas a la jurisdicción, el acceso a los tribunales extranjeros y el reconocimiento de los procedimientos extranjeros, de un modo que no impidiera preparar una convención”¹.

II. Resumen de las deliberaciones anteriores del Grupo de Trabajo

3. Tal vez el Grupo de Trabajo también desee recordar los documentos de trabajo preparados para períodos de sesiones anteriores, en que se examinaron aspectos de los grupos de empresas y el centro de los principales intereses en el contexto de la

¹ Véase A/CN.9/WG.V/WP.93/Add.1, párr. 8, y *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17*, A/65/17, párr. 259 a).

tercera parte de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia y que son los siguientes: A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.2 (párrs. 5 a 12); A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.2 (párrs. 2 a 17); A/CN.9/WG.V/WP.82/Add.4 (párrs. 10 a 15); A/CN.9/WG.V/WP.85/Add.1 (párrs. 3 a 13); A/CN.9/WG.V/WP.99 (párrs. 55 a 64); y A/CN.9/738 (párrs 36 y 37).

4. Aunque no es posible repetir el contenido de esos documentos, tal vez el Grupo de Trabajo desee recordar las conclusiones a que llegó tras examinar ese contenido durante sus períodos de sesiones 31° a 36° y 40°.

5. En su 31° período de sesiones, el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión (A/CN.9/618, párr. 54) de que las dificultades para convenir una definición del centro de los principales intereses de un grupo de empresas implicaban que era necesario centrarse en la forma de facilitar la coordinación y cooperación entre los diversos tribunales ante los que pudieran entablarse procedimientos de insolvencia contra distintas empresas de un grupo, al tiempo que se reconocía la conveniencia de evitar una multiplicidad de procedimientos en el contexto de los grupos de empresas.

6. En sus períodos de sesiones 32°, 33° y 34°, el Grupo de Trabajo dedicó un tiempo limitado a examinar cuestiones internacionales, en particular a intentar determinar la manera de proceder y la forma en que podrían examinarse las cuestiones pertinentes.

7. En su 35° período de sesiones, el Grupo de Trabajo acordó en general (A/CN.9/666, párrs. 26 y 27), que, aunque tal vez fuera conveniente, sería difícil concertar una definición del centro de los principales intereses de un grupo de empresas que pudiese utilizarse, por ejemplo, para limitar la apertura de procedimientos paralelos o para simplificar el número de legislaciones aplicables a procedimientos de insolvencia entablados en distintos Estados respecto de empresas de un mismo grupo. Uno de los problemas principales sería el grado en que los tribunales interesados aceptarían, adoptarían y aplicarían voluntariamente una definición de esa índole. Convino también en que sería difícil utilizar el centro de los principales intereses de un grupo de empresas para aplicar a este en su conjunto el régimen del reconocimiento previsto en la Ley Modelo, en lugar de aplicarlo a cada una de las empresas que lo integraran. El Grupo de Trabajo llegó a las siguientes conclusiones (A/CN.9/666, párr. 32): que la presunción establecida en el artículo 16 3) de la Ley Modelo no era aplicable directamente en el contexto de los grupos de empresas; que podría ser útil formular una regla sobre el centro de los principales intereses de un grupo de empresas, a fin de facilitar la coordinación entre los múltiples procedimientos de insolvencia entablados contra empresas pertenecientes al grupo, que en esa regla podría establecerse una presunción rebatible, del tenor de la enunciada en el artículo 16 3) de la Ley Modelo, para determinar la sede de la empresa que controla el grupo, y que los factores pertinentes para rebatir la presunción (que deberían examinarse en su conjunto) se basaran en los factores enunciados en los párrafos 6 y 13 del documento A/CN.9/WG.V/WP.82/Add.4.

8. En el párrafo 6 se señalaron factores como el grado de independencia de una filial con respecto a sus decisiones financieras, de gestión y de política; los arreglos financieros entre la empresa matriz y la filial, en particular en lo relativo a la estructura del capital, la ubicación de las cuentas bancarias y los servicios de

contabilidad; la distribución de la responsabilidad en lo concerniente a la documentación técnica y jurídica y a la firma de los contratos, y el lugar en que se encuentran los centros de diseño, comercialización, fijación de precios, entrega de productos y funciones administrativas.

9. El párrafo 13 se refería a los factores que podrían ser pertinentes a efectos de establecer el grado de integración necesario para determinar la sede de la empresa que controla un grupo muy integrado. Se sugirió que dichos factores podrían ser los siguientes: el grado de independencia de las empresas del grupo con respecto a las decisiones financieras, de gestión y de política (las “funciones de jefe de la oficina”); los arreglos financieros entre las empresas del grupo, en particular con respecto a la estructura del capital, la ubicación de las cuentas bancarias y los servicios de contabilidad; la distribución de la responsabilidad en lo concerniente a la documentación técnica y jurídica de la empresa y a la firma de los contratos, y el lugar en que se encuentren los centros de diseño, comercialización, fijación de precios, entrega de productos y funciones administrativas, así como la impresión que tuviesen los terceros, en particular los acreedores, sobre ese lugar. En el párrafo 15 de la introducción a la tercera parte de la Guía Legislativa se esbozan también los factores que podrían ser pertinentes para determinar el grado de integración de un grupo de empresas.

10. Durante el 36º período de sesiones del Grupo de Trabajo, tras un nuevo examen de la idea de un centro de coordinación, se expresó la opinión (A/CN.9/671, párrs. 18 y 19) de que la determinación del centro de coordinación de un grupo de empresas entrañaba una serie de dificultades dimanantes de la necesidad de determinar el centro de los principales intereses de cada deudor en particular. Estas se referían, en especial, a la determinación del Estado que debería adoptar la decisión con respecto a la ubicación del centro de coordinación, y a la cuestión de si esa decisión sería vinculante o, al menos, reconocida en otros Estados.

11. Otras dificultades eran las siguientes: la de tener que velar por que ese centro cumpliera funciones de índole procesal y no sustantiva; la necesidad de darle flexibilidad suficiente para que tuviera en cuenta las particularidades de cada caso; la de actuar con rapidez al designar un centro de coordinación, lo que aconsejaba evitar la utilización de criterios complejos; la necesidad de evitar la búsqueda interesada del foro más conveniente; la conveniencia de definir la función que procediera encomendar a la entidad coordinadora; la de evitar nombrar un centro de coordinación salvo cuando ello resultara útil o necesario para lograr la reorganización global de un grupo; y la necesidad de distinguir entre el cometido de los tribunales en materia de coordinación y cooperación y el de la empresa coordinadora. Con respecto a este último punto, se observó que en su anterior período de sesiones el Grupo de Trabajo no había examinado si esa coordinación debería ser establecida y dirigida por el tribunal encargado de sustanciar el procedimiento respecto de la empresa coordinadora o por el representante de la insolvencia interesado. Se convino en general (A/CN.9/671, párr. 20) en que la decisión por la que un tribunal determinara el centro de coordinación no debería ser vinculante para otros Estados.

12. Aunque se expresó cierto apoyo a la idea de conservar una recomendación sobre la determinación del centro de coordinación de un grupo de empresas, el Grupo de Trabajo no logró definir una función clara para dicho centro, que complementara las recomendaciones más generales sobre coordinación y cooperación entre los

tribunales y los representantes de la insolvencia que se había acordado incorporar en la tercera parte de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia. Tras haber examinado los demás proyectos de recomendación de la tercera parte, el Grupo de Trabajo volvió al tema del centro de coordinación, y convino (A/CN.9/671, párr. 23) en suprimir los proyectos de recomendación 1 y 2 (en que se preveía la presunción para determinar el centro de coordinación), debido a que la determinación de ese centro no tendría ningún efecto jurídico, por el carácter no vinculante de esa determinación. Sin embargo, el Grupo de Trabajo reconoció la utilidad de que una entidad asumiese una función rectora en la cooperación, y convino en señalar en el comentario la importancia de que una de las entidades del grupo asumiese funciones de coordinación². Esa cuestión se abordó posteriormente en la versión final de la recomendación 250, en que se prevé la posibilidad de que en la cooperación entre representantes de la insolvencia uno de ellos asuma una función de coordinación. El enfoque adoptado en último término en la tercera parte consistió en centrarse en fomentar la cooperación y la coordinación entre procedimientos de insolvencia transfronteriza dirigidos contra dos o más miembros de un grupo de empresas, basándose en las disposiciones de la Ley Modelo sobre cooperación y coordinación (artículos 25 a 27).

13. En su 40º período de sesiones, el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión (A/CN.9/738, párrs. 36 y 37) de que en las revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relativas a ciertos aspectos del centro de los principales intereses se debería hacer referencia a la tercera parte de la Guía Legislativa y a las soluciones adoptadas para el trato otorgable a los grupos de empresas en situaciones de insolvencia, especialmente en el contexto internacional. En el párrafo 9 del documento A/CN.9/WG.V/112 se pidió al Grupo de Trabajo que examinara la cuestión del contenido de esa referencia. Sin embargo, al margen de ella y especialmente en relación con el concepto del centro de los principales intereses de un grupo de empresas, durante el 40º período de sesiones se señaló que, cuando el Grupo de Trabajo hubiese llegado a un acuerdo sobre los factores importantes para determinar el centro de los principales intereses de un deudor determinado, tal vez sería posible estudiar más a fondo la cuestión de los grupos de empresas y, en

² Tal vez el Grupo de Trabajo desee observar el enfoque adoptado en la labor destinada a elaborar principios para la coordinación de la insolvencia de grupos de empresas multinacionales, realizada por el *International Insolvency Institute* (la documentación correspondiente puede consultarse en el sitio www.iiiglobal.org/component/jdownloads/viewcategory/558.html). Se prevé aplicar dichos principios a los grupos de empresas cuyos miembros, actividades, activos y empleados estén situados en más de un país y en los que exista un régimen de gestión empresarial unificado, por la existencia de una red común o interconectada de participación en el capital social o en virtud de un contrato. Los principios se orientan a determinar el “centro del grupo”, que sería la jurisdicción desde la que se dirigirían las operaciones de una empresa multinacional integrada, a fin de determinar la jurisdicción cuya competencia deberían reconocer otras jurisdicciones, en la medida en que lo permitiese la ley, cuando se tratara de cuestiones relativas a la maximización del valor de los bienes. Los factores que se deben considerar para determinar si existe el grado pertinente de integración son los que se enuncian en la Guía Legislativa y se señalan más arriba. Las directrices 1 a 11 se refieren a la notificación y el derecho de comparecer; la comunicación; la coordinación y los protocolos; el aplazamiento de determinadas decisiones sobre la apertura; y los representantes únicos de la insolvencia. Las directrices 12 a 22, que se refieren a la determinación del centro del grupo de empresas y sus efectos, son indicativas, y se señala que deberían aplicarse mediante legislación.

particular, la pertinencia de esos factores en el contexto de un grupo de empresas (las revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza, incluidos los factores pertinentes a la determinación del centro de los principales intereses, figuran en el documento A/CN.9/WG.V/WP.112).

III. Novedades en el trato otorgable a los grupos de empresas en situaciones de insolvencia

14. El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que no hay certeza respecto de que la práctica actual en lo tocante a los grupos de empresas haya evolucionado en una dirección nueva que indique una solución de los problemas ya determinados en relación con el centro de los principales intereses y los grupos de empresas. De cualquier modo, la práctica reciente indica que ha aumentado la coordinación y la cooperación, en un grado que se ajusta bastante a las recomendaciones de la tercera parte de la Guía Legislativa en que se abordan los procedimientos transfronterizos múltiples que afectan a los miembros de un determinado grupo de empresas. En varias jurisdicciones se ha promulgado legislación basada en la tercera parte de la Guía Legislativa³, que se ha señalado como fuente de inspiración en el contexto de la insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas (véase, en general, el documento A/CN.9/WG.V/WP.109), para facilitar la cooperación y la comunicación transfronterizas.

15. Tal vez el Grupo de Trabajo desee tomar nota de las propuestas recientes de revisión del Reglamento (CE) núm. 1346/2000 del Consejo Europeo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, las cuales son bastante compatibles con las recomendaciones de la tercera parte. En esas propuestas se prevé la coordinación de los procedimientos de insolvencia relativos a distintos miembros de un grupo de empresas por el expediente de obligar a los representantes de la insolvencia y a los tribunales que se ocupen de los distintos procedimientos principales a cooperar y comunicarse entre sí. Además, los representantes de la insolvencia que participen en esos procedimientos dispondrán de los instrumentos procesales para solicitar la suspensión de los demás procedimientos y proponer un plan de reorganización en beneficio de los miembros del grupo sujetos a procedimientos de insolvencia.

16. Aunque en un nuevo considerando se aclaran las circunstancias en que puede impugnarse la presunción de que el centro de los principales intereses de una persona jurídica se encuentra en el lugar en que se halla su domicilio social (el texto de ese considerando se ha tomado del dictamen sobre *Interedil*⁴ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), se ha mantenido el enfoque de determinar el centro de los principales intereses de los miembros del grupo de empresas en función de cada entidad. Sin embargo, se proponen varias modificaciones, cuyo objetivo es dar más eficiencia a la administración del patrimonio del deudor en situaciones en que este tenga un establecimiento en otro Estado Miembro. El tribunal al que se solicite

³ En Colombia, se promulgó el Decreto 1749, de 2011; a comienzos de enero de 2013, el Ministerio de Justicia de Alemania publicó un proyecto de análisis de la insolvencia de grupos de empresas, que parece inspirarse en la tercera parte.

⁴ *Interedil Srl, en liquidación*, Caso C_396/09, juicio de 20 de octubre de 2011.

que abra un procedimiento secundario debería estar en condiciones de rechazar esa solicitud, si lo solicitara el representante de la insolvencia en el procedimiento principal, o de aplazar su decisión sobre esa apertura si dicho procedimiento no fuese necesario para proteger los intereses de los acreedores locales. Además, ese tribunal estaría obligado a escuchar al representante de la insolvencia en el procedimiento principal antes de abrir el procedimiento secundario. No se verá afectada la facultad del representante de la insolvencia de solicitar la apertura de un procedimiento secundario cuando ello facilite la administración de casos complejos.

IV. Próximas medidas

17. Tal vez el Grupo de Trabajo desee examinar el enfoque que le convendría adoptar para examinar la cuestión de la forma de facilitar más el trato transfronterizo otorgable a los grupos de empresas habida cuenta de las observaciones anteriores, y teniendo en consideración el mandato ampliado del Grupo de Trabajo en lo que respecta a la elaboración de una posible ley modelo, de disposiciones o de un tratado sobre cuestiones de jurisdicción, acceso y reconocimiento.

J. Nota de la Secretaría sobre los grupos de empresas — Obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43° período de sesiones

(A/CN.9/WG.V/WP.115)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-7
II. Diferentes enfoques nacionales de las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia en el contexto de los grupos de empresas	8-39
A. Argentina	8-11
B. Australia	12-14
C. Bélgica	15-16
D. Brasil	17-18
E. Colombia	19-21
F. Francia	22-24
G. Alemania	25-26
H. Italia	27-31
I. España	32-33
J. Suiza	34-35
K. Estados Unidos de América	36-39
III. Cuestiones que deben examinarse	40-41

I. Introducción

1. En su 42° período de sesiones (celebrado en noviembre de 2012), el Grupo de Trabajo examinó las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia (A/CN.9/763, párrs. 66 a 91) basándose en la información contenida en el documento A/CN.9/WG.V/WP.108, en el que también figuraba información sobre cuestiones relativas a los directores de empresas pertenecientes a un grupo en el período cercano a la insolvencia (A/CN.9/WG.V/WP.108, párrs. 52 a 60). El Grupo de Trabajo convino en que si bien este último tema planteaba cuestiones difíciles y complejas, particularmente en cuanto a los aspectos que vinculaban a la insolvencia con el derecho de sociedades, la posibilidad de una futura labor al respecto merecía examinarse con suma atención una vez que se hubiera terminado el examen de las recomendaciones 1 a 10 y el comentario correspondiente. A solicitud del Grupo de Trabajo, la Secretaría ha preparado el presente documento sobre los distintos enfoques y soluciones nacionales relativos a las obligaciones de los directores en el

contexto de un grupo de empresas en el período cercano a la insolvencia¹ a fin de proporcionar información complementaria y facilitar las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre el tema (A/CN.9/763, párr. 92).

2. El Grupo de Trabajo recordará que al preparar la tercera parte de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia había reconocido que era cada vez más frecuente que la actividad mercantil de las sociedades se gestionara en el marco de grupos de empresas. Según se explicó, los grupos de empresas abarcaban distintas formas de organización económica edificadas sobre la base de la entidad jurídica individual y compuestas de dos o más entidades jurídicas cuya vinculación consistía en alguna forma de control directo o indirecto o de participación en su capital social respectivo. Se reconoció que los grupos de empresas estaban omnipresentes tanto en los mercados desarrollados como en los incipientes, y presentaban la característica común de llevar a cabo sus operaciones en un gran número de sectores que con frecuencia no eran afines; algunas veces pertenecían a una familia y combinaban esa forma de propiedad con distintos grados de participación de inversionistas externos. Además, se dijo que las principales entidades económicas del mundo no eran solo Estados, sino también diversos grupos de empresas multinacionales que podían generar un porcentaje elevado del producto nacional bruto a escala mundial y cuyas tasas de crecimiento anual y volumen de operaciones sobrepasaban los de muchos Estados².

3. En su anterior período de sesiones (celebrado en noviembre de 2012), el Grupo de Trabajo reconoció diversas cuestiones que podían plantearse con respecto a las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia en el contexto de un grupo (A/CN.9/WG.V/WP.108, párr. 52). Se señalaron en particular dos cuestiones principales a fin de someterlas a examen y debate, a saber:

- i) cuál es la definición adecuada de director y las circunstancias en que las otras empresas del grupo pueden quedar integradas en esa definición, especialmente cuando entra en juego la relación entre la sociedad matriz y las filiales de propiedad total o controladas (A/CN.9/WG.V/WP.108, párrs. 58 y 59); y
- ii) si debe prevalecer el principio de la entidad individual y sus consecuencias cuando haya conflicto entre la actuación en interés de la empresa de la que se sea director y los intereses del grupo al que esa empresa pertenece (A/CN.9/WG.V/WP.108, párrs. 53 a 57).

4. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar el análisis que figura en el documento A/CN.9/WG.V/WP.113 con respecto a las personas en quienes recaen las obligaciones en el período cercano a la insolvencia (párrs. 26 a 29 y recomendación 4), denominadas “directores” en el presente documento.

¹ La Secretaría basó este documento en los estudios disponibles existentes sobre el tema de las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia y sobre toda información adicional en el contexto de los grupos de empresas (en particular, INSOL, *Directors in the Twilight Zone III*, 2009), así como en la información presentada a la Secretaría por algunos Estados Miembros. Solo se incluyeron en este documento los Estados respecto de los cuales se disponía de información pertinente proveniente de esas fuentes.

² Tercera parte de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia (Trato otorgable a los grupos de empresas en situaciones de insolvencia), Sección IA, párrs. 2, 4 y 5, y párrs. 1 a 39 en general.

5. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar también la información preparada para su consideración en el anterior período de sesiones (A/CN.9/WG.V/WP.108, párr. 53), en la que se indicaba que si bien los intereses de un miembro del grupo tenían particular importancia cuando la solvencia de ese miembro del grupo de empresas pudiera plantear un problema o se convirtiera en un problema después de realizada una operación destinada a beneficiar al grupo en su totalidad, la estructura del grupo podía exigir que los directores actuaran en beneficio de todo el grupo. En ese contexto, los directores tendrían que equilibrar los intereses de su propia empresa con los objetivos o necesidades económicas del grupo en su conjunto, que posiblemente fueran opuestos. Podrían mencionarse como ejemplos de posibles conflictos de ese tipo los casos en que una empresa del grupo realizara un préstamo a otra empresa del mismo grupo o saliera de garante de un préstamo concedido a otra empresa del grupo por un prestamista externo; o en que una empresa del grupo concertara un acuerdo con otra empresa del mismo grupo para transferirle su negocio o sus activos o para cederle una oportunidad comercial o para concertar un contrato con esa empresa en términos que no se pudieran considerar comercialmente viables; o en que una empresa del grupo saliera de garantía cruzada de otras empresas del mismo grupo para ayudar al grupo a aprovechar mejor sus activos en la financiación de las operaciones del grupo en sí. El problema que puede plantearse con respecto a estas operaciones resulta de la relación entre las partes en la operación o su posición dentro del grupo, y debido a que el carácter de la operación implica una distribución de beneficios y perjuicios que no se ajusta a lo que generalmente se consideraría comercialmente viable.

6. El Grupo de Trabajo tal vez desee recordar también que la información suministrada en su anterior período de sesiones indicaba que el tratamiento de estas cuestiones es muy diferente de una jurisdicción a otra, en especial con respecto a los deberes de los directores para con la compañía en el período cercano a la insolvencia, y la manera en que esos directores deben evaluar el interés de la empresa en un contexto de grupo (A/CN.9/WG.V/WP.108, párrs. 54 a 57).

7. En el análisis que figura a continuación se examina la legislación de varias jurisdicciones en la medida en que se ocupa de:

- i) las obligaciones de los directores en el contexto de una empresa que forma parte de un grupo; y
- ii) toda consideración particular de esas obligaciones en el contexto de la insolvencia o del período cercano a esta.

II. Diferentes enfoques nacionales de las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia en el contexto de los grupos de empresas

A. Argentina

8. La Ley de Sociedades Comerciales de la Argentina impone una obligación fiduciaria general a los directores de empresas solventes, que los obliga a actuar de

buena fe y con la diligencia de un buen hombre de negocios³. Por consiguiente, los directores tienen la obligación de ser leales y diligentes al administrar la empresa. La Ley no contiene ningún régimen especial para un grupo de empresas, ni tampoco una definición del término.

9. Conforme a la Ley de Concursos y Quiebras de la Argentina⁴, la zona de insolvencia se extiende a los actos practicados hasta un año antes de la fecha de la declaración de cesación de pagos⁵. En cuanto a la responsabilidad de las personas físicas, la Ley de Concursos y Quiebras abarca a los representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocios que hubieren producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia⁶. La Ley no contiene ninguna disposición especial para grupos de empresas.

10. No obstante, los grupos de empresas se tienen en cuenta en la Ley de Concursos y Quiebras en lo que respecta a la extensión del procedimiento de insolvencia. De hecho, la insolvencia puede extenderse a toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando haya desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte⁷. La Ley de Concursos y Quiebras proporciona a estos efectos la siguiente definición de persona controlante⁸: i) la que en forma directa o por intermedio de una sociedad a su vez controlada, posee participación por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social⁹; o ii) cada una de las personas que, actuando conjuntamente, poseen participación por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social¹⁰. Las obligaciones de los directores durante el procedimiento de insolvencia no se especifican, pero el régimen general de deberes asumibles cuando la empresa es solvente sigue siendo aplicable.

11. La Ley de Concursos y Quiebras de la Argentina también prevé un régimen especial para la insolvencia de un grupo de empresas: pueden iniciar un procedimiento de insolvencia dos o más personas físicas o jurídicas que integren en forma permanente un conjunto económico¹¹. Dado que los deberes de los directores siguen siendo los mismos, se plantea la pregunta de si esos deberes pueden evaluarse sobre la base de los intereses de todo el grupo.

B. Australia

12. Cuando una empresa está en liquidación, a diferencia del período cercano a la insolvencia, los directores en Australia tienen la obligación de prevenir el comercio

³ Ley 19.550 de Sociedades Comerciales de 20 de marzo de 1984, Boletín Oficial de 30 de marzo de 1984, artículo 59.

⁴ Ley 24.522 de Concursos y Quiebras de 20 de julio de 1995, Boletín Oficial 28.203 de 9 de agosto de 1995.

⁵ Ley de Concursos y Quiebras de la Argentina, artículo 174.

⁶ Ley de Concursos y Quiebras de la Argentina, artículo 173.

⁷ Ley de Concursos y Quiebras de la Argentina, artículo 161 2).

⁸ *Ibid.*

⁹ Ley de Concursos y Quiebras de la Argentina, artículo 161 2) a).

¹⁰ Ley de Concursos y Quiebras de la Argentina, artículo 161 2) b).

¹¹ Ley de Concursos y Quiebras de la Argentina, artículo 65.

insolvente de la empresa, y deberán responder personalmente por cualquier incumplimiento de esa obligación, siempre que se cumplan determinados requisitos¹². También se puede considerar responsable a una sociedad de carteras por el comercio insolvente de su filial, pero esa responsabilidad no se extiende a los directores de la sociedad de carteras¹³.

13. En lo que respecta a un grupo de empresas, los intereses que deben tener en cuenta los directores dependen de si la empresa es solvente o insolvente. Un grupo de empresas se ha definido en el derecho consuetudinario como “una configuración de varias empresas ligadas por una red común o interconectada de participaciones en el capital social, y a la vez sujetas a un control unificado o a una capacidad de controlar”¹⁴. Si la empresa es solvente, los directores están facultados para considerar los intereses de las empresas como grupo al determinar si el mejor interés de la empresa que dirigen se vería satisfecho con las medidas que proponen¹⁵, siempre que los intereses del grupo sigan siendo compatibles con los de esa empresa¹⁶. Si el grupo en su conjunto es insolvente, los intereses de la empresa a raíz de cualquier operación problemática se apartarían considerablemente de los intereses del grupo¹⁷. Si por culpa de los directores la empresa perjudicara los intereses de sus acreedores en circunstancias de insolvencia, esos directores no estarían cumpliendo con su deber de actuar en el mejor interés de esa empresa¹⁸.

14. El caso Bell proporciona un buen resumen de lo que se espera de los directores en un contexto de grupo que se enfrenta a la insolvencia: los directores no deben ignorar los intereses del grupo más amplio pero tienen que tener en cuenta los intereses de cada una de las empresas cuando una o más de las empresas que forman parte de un grupo realicen una operación¹⁹. En este caso, se sostuvo que los directores habían expuesto a las empresas a una probable perspectiva de pérdida sin perspectivas probables de ganancia al concentrarse en el grupo sin mirar por los intereses de cada una de las empresas²⁰.

C. Bélgica

15. La legislación belga impone a los directores el deber de actuar en pro del interés social de la empresa y no en el de un accionista en particular o en el de los acreedores de la empresa. La definición de “interés social” es interpretada por los tribunales sobre la base de cada caso en particular²¹. Aunque los intereses de una

¹² Ley de Sociedades de 2001 (Cth), Sección 588G.

¹³ Ley de Sociedades de 2001 (Cth), Sección 588V.

¹⁴ *Walker c. Wimborne & Ors* (1976) 3 ACLR 529 en 532 (Mason J).

¹⁵ *Westpac Banking Corporation c. Bell Group Ltd.* (en liquidación) (núm. 3) [2012] WASCA 157 en 952 (Lee AJA); *Neat Domestic Trading Property Ltd. c. AWB Ltd.* [2003] HCA 35 [47]; (2003) 216 CLR 277 (McHugh, Hayne, Callinan JJ).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Westpac Banking Corporation c. Bell Group Ltd.*, nota 15 *supra* en 952.

¹⁸ *Ibid* y *Walker c. Wimborne & Ors*, nota 14 *supra* en 532.

¹⁹ *The Bell Group Ltd. c. Westpac Banking Corporation* (núm. 9) [2008] WASC 239 en [4621] (Owen J).

²⁰ *Ibid* en [9746].

²¹ International Insolvency Institute, Committee on Corporate and Professional Responsibility, Survey on Director and Officer Duties, Responsibilities, and Accountability, Bélgica (Nora Wouters), pág. 2.

empresa belga suelen coincidir con los intereses de todo el grupo, dependiendo de las circunstancias, los directores de esa empresa tal vez tengan que actuar con mayor independencia del grupo²².

16. Al equilibrar el interés social de una empresa con el interés general del grupo, la legislación belga se refiere a los principios establecidos en el derecho consuetudinario francés para evaluar si determinada operación está bien equilibrada en lo que respecta al interés social (véase Francia, párrs. 22 a 24 *infra*).

D. Brasil

17. La legislación brasileña introdujo la posibilidad de crear un grupo contractual de sociedades. El grupo de sociedades nace de un contrato celebrado entre una sociedad controladora y una o varias sociedades controladas, en virtud del cual se comprometen a combinar recursos o esfuerzos para la consecución de los respectivos objetivos, o a participar en actividades o emprendimientos comunes²³.

18. Aunque cada sociedad conserva su capacidad jurídica y sus propios activos²⁴, el grupo de sociedades puede definir su estructura administrativa y los poderes, deberes y responsabilidades de sus directores²⁵. Los directores de las filiales deben actuar dentro de los límites de los poderes y los deberes determinados por los estatutos y el contrato social, y deben observar las instrucciones emitidas por los directores del grupo que no impliquen una violación de las obligaciones legales o contractuales²⁶. Al parecer, se exige que los directores tengan en cuenta el interés del grupo en su conjunto al evaluar la posibilidad de realizar determinada operación.

E. Colombia

19. Colombia ha establecido por ley una definición de grupo empresarial. Una sociedad subordinada o controlada es aquella cuyo poder de decisión se encuentra sometido a la voluntad de otra u otras personas, ya sea directa o indirectamente²⁷. El Código de Comercio también define a un grupo empresarial como aquel en el que existe una unidad de propósito y dirección, es decir, cuando haya un objetivo común determinado por la sociedad matriz o controlante en virtud del control y la dirección que ejerce sobre el grupo en su conjunto, sin perjuicio de que cada entidad tenga una actividad o un propósito diferentes²⁸.

20. No existen obligaciones especiales de los directores en el contexto de un grupo de empresas, pero cada director sigue estando sometido a un deber general de obrar de buena fe y con lealtad, y deberá administrar la empresa de la que es director con la diligencia de un buen hombre de negocios²⁹.

²² *Ibid.*, pág. 3.

²³ Ley 6404/76 de 15 de diciembre de 1976, artículo 265.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, artículo 272.

²⁶ *Ibid.*, artículo 273.

²⁷ Código de Comercio de Colombia, artículo 260.

²⁸ *Ibid.*, artículo 261.

²⁹ Ley 222 de 1995 (20 de diciembre de 1995), artículo 23.

21. En caso de insolvencia, la sociedad matriz responderá por las obligaciones de la sociedad subordinada si la insolvencia o la liquidación se ha producido por causa de las actuaciones que haya realizado en interés de la sociedad controlante o de cualquier otra subordinada, y en contra del beneficio de la sociedad insolvente³⁰. Se presume que la sociedad está en situación de insolvencia por las actuaciones derivadas de ese control, a menos que se demuestre lo contrario³¹.

F. Francia

22. En Francia, la jurisprudencia ha definido a un grupo de empresas como la situación en que determinadas empresas están unidas por un vínculo de dependencia y un control unificado³². Los propósitos de las diferentes empresas no tienen por qué ser idénticos, siempre que exista cierta subordinación de cada entidad jurídica en beneficio del objetivo financiero común del grupo³³.

23. Para que se considere que los directores han cumplido con sus deberes, las operaciones entre las empresas del grupo i) deben tener un interés financiero, económico o social común que se aprecie a la luz de una política elaborada para ese grupo en su conjunto; y ii) no deben efectuarse sin contrapartida ni rompiendo el equilibrio entre los compromisos respectivos de las distintas empresas, ni exceder las posibilidades financieras de la empresa que soporta la carga de la operación³⁴.

24. El interés de cada una de las empresas es la regla principal para evaluar la validez de la operación. No obstante, al parecer el contexto del grupo es un factor que puede influir en el resultado final en lo relativo al cumplimiento de los deberes de los directores para con la empresa.

G. Alemania

25. En el derecho alemán, se ha introducido el concepto de “responsabilidad del grupo” para crear una obligación aplicable a un director que sea también accionista con participación dominante, a fin de compensar toda pérdida debida al abuso de poder de los directivos³⁵. El Tribunal Federal de Alemania ha sostenido que este régimen se aplica también cuando el accionista es una persona física³⁶: el director, que era también el único accionista, había dirigido la empresa persiguiendo únicamente sus intereses personales, y esta era considerada como una “empresa dominante”, concepto que se equiparaba al de la responsabilidad en un grupo de sociedades.

26. La doctrina de levantar el velo del secreto empresarial se ha definido por otra parte como una responsabilidad por falta civil del director de la empresa cuando la dirección haya inducido a una filial a aceptar asistencia financiera que haya podido

³⁰ Ley 1116 de 2006 (27 de diciembre de 2006), artículo 61.

³¹ *Ibid.*

³² Cour de cassation [Tribunal Supremo de Francia] Chambre Criminelle, 4 de febrero de 1985, núm. 84-91581.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ INSOL, Directors in the Twilight Zone III, nota 1 *supra*, pág. 321.

³⁶ *Ibid.*

tener como consecuencia que esta cayera en la insolvencia³⁷. En consecuencia, el director tiene la obligación, en el período cercano a la insolvencia, de proteger la supervivencia de la empresa independientemente de la existencia de un grupo³⁸.

H. Italia

27. Si bien en el derecho italiano aún no se han aprobado disposiciones especiales relativas a los deberes de los directores en el seno de un grupo de empresas en el período cercano a la insolvencia, el Código Civil contiene disposiciones relativas a la responsabilidad de las empresas matrices y sus directores por daños causados a los accionistas o acreedores de las filiales³⁹. Las entidades jurídicas que ejerzan facultades de “dirección y coordinación” sobre una empresa italiana pueden ser considerados responsables frente a los accionistas minoritarios y los acreedores de la filial por abuso de esas facultades cuando la empresa de control actúe en su propio interés o en el interés de terceros⁴⁰.

28. Si bien el concepto de “dirección y coordinación” aún no se ha interpretado judicialmente, los comentaristas opinan que habrá facultades de “dirección y coordinación” cuando una parte importante de las decisiones administrativas que corresponden a la filial sean adoptadas en forma continua y sustantiva por la gestión de la entidad de control, incluso si las decisiones son aplicadas formalmente por la gestión de la filial. Esta legislación se aplica también al caso en que esas facultades se ejerzan conforme a cualquier estatuto o arreglo especial.

29. Este régimen de responsabilidad se extiende también a todas las personas que estén de acuerdo o se beneficien con la mala gestión (como los directores de la entidad de control u otra de sus filiales), y esas personas pueden ser consideradas responsables solidarias⁴¹. No obstante, podrán ser eximidas de responsabilidad cuando esos daños se reparen totalmente, incluso mediante operaciones posteriores realizadas con ese fin específico, o cuando los daños se vean compensados por el efecto general de las actividades de dirección y coordinación en la filial⁴².

30. Además, las partes perjudicadas (acreedores y accionistas minoritarios) podrán entablar juicio contra la sociedad de control y sus directores solo cuando no puedan recibir indemnización de la filial⁴³. Por consiguiente, esta acción podrá limitarse en la práctica al caso en que la filial haya caído en la insolvencia.

31. Por último, en un contexto de grupo, los directores de la empresa matriz podrán ser responsabilizados solidariamente con los directores de la filial por los

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, pág. 322.

³⁹ INSOL, Directors in the Twilight Zone III, nota 1 *supra*, págs. 446 a 448.

⁴⁰ Código Civil italiano, artículo 2497. El control se define en el artículo 2359 del Código Civil italiano como la situación en que una empresa puede: i) ejercer una influencia particular en la asamblea general de accionistas de otra empresa, ya sea que disponga de la mayoría de los derechos de voto o no, o ii) ejercer una influencia particular sobre la empresa controlada en virtud de los vínculos contractuales existentes entre esas dos empresas.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² INSOL, Directors in the Twilight Zone III, nota 1 *supra*, pág. 448.

⁴³ Código Civil italiano, artículo 2497.

daños causados a la filial insolvente debido a un abuso de los poderes de dirección en el seno del grupo⁴⁴.

I. España

32. En el derecho español, se ha definido a un grupo de sociedades como la situación en que una sociedad ostenta o puede ostentar, directa o indirectamente, el control de otra sociedad, en lo que respecta a derechos de voto o nombramiento de los miembros del órgano de administración de la sociedad dependiente, ya sea debido a que posee acciones que le dan derechos de voto o debido a cualquier otro acuerdo⁴⁵.

33. Conforme al derecho español, los directores están sujetos a un deber de lealtad, que debe ejercerse a la luz del interés social, entendido como interés de la propia sociedad⁴⁶. Según la doctrina académica, el derecho español reconoce la existencia y legitimidad de un grupo de empresas, pero sigue siendo difícil evaluar si el interés de una empresa puede extenderse para abarcar el interés del grupo en su conjunto⁴⁷.

J. Suiza

34. En el derecho suizo no existe ninguna disposición relativa al trato otorgable a los grupos de empresas en el ámbito del derecho de sociedades o del régimen de la insolvencia, con excepción de algunas disposiciones específicas sobre derecho contable y bancario. La principal pregunta en lo que respecta a las obligaciones del director de una empresa que forme parte de un grupo es si la subordinación de los intereses de la empresa controlada a los intereses del grupo en su conjunto puede calificarse como incumplimiento de los deberes del director. Este análisis no se modifica exista o no insolvencia.

35. En general, el Tribunal Supremo Federal de Suiza adopta una posición conservadora, y sostiene que los intereses de la empresa deben considerarse desde la perspectiva de cada una de las empresas que la componen y no desde la del grupo en su conjunto⁴⁸. Esta opinión fue confirmada recientemente por el Tribunal⁴⁹: la responsabilidad de un miembro de la junta directiva de la sociedad matriz, que era también miembro de la junta directiva de la filial, se confirmó porque la sociedad matriz, que cayó posteriormente en la insolvencia, había otorgado un préstamo a su filial que en ese momento ya había caído en la insolvencia. Se sostuvo que ese traspaso de los bienes de la sociedad matriz a una filial debía considerarse como un incumplimiento de la obligación para con la sociedad matriz si no había

⁴⁴ INSOL, Directors in the Twilight Zone III, nota 1 *supra*, pág. 448.

⁴⁵ Código de Comercio de España, artículo 42.

⁴⁶ Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital), artículo 226.

⁴⁷ José Miguel Embrid Irujo, "Apuntes sobre los deberes de fidelidad y lealtad de los administradores de las sociedades anónimas" (2006) 46 Cuadernos de Derecho y Comercio 9.

⁴⁸ Bundesgericht [Tribunal Supremo Federal de Suiza] BGE 138 II 57, 61; BGE 130 III 213, 216 y siguientes.

⁴⁹ Bundesgericht [Tribunal Supremo Federal de Suiza] 4A_74/2012 (18 de junio de 2012).

perspectivas de reembolso. Además, el hecho de ser un director de ambas empresas sujetaba al miembro de la junta a un control más estricto con respecto a su responsabilidad por las operaciones interiores del grupo, dado que se estimaba que estaba mejor informado que cualquier parte externa sobre la situación financiera de ambas empresas y los riesgos relacionados con la operación.

K. Estados Unidos de América

36. En los Estados Unidos⁵⁰, se ha sostenido que el núcleo de las obligaciones de los directores se traslada en cierta forma cuando una empresa cae en la insolvencia. En una empresa solvente, los directores tienen obligaciones fiduciarias con respecto a la empresa y sus accionistas⁵¹ y generalmente no directamente con respecto a los acreedores⁵². No obstante, se ha sostenido que, cuando se produce la insolvencia, las obligaciones fiduciarias de los directores se reorientan al menos parcialmente para incluir a los acreedores de la empresa⁵³. Si bien se ha dicho que la cuestión de a quién se deben las obligaciones fiduciarias durante la insolvencia es un tema sujeto a considerable debate y confusión⁵⁴, hay amplio acuerdo en el sentido de que los tribunales deberían conceder algunos derechos adicionales a los acreedores cuando una empresa sea insolvente o se halle en el período cercano a la insolvencia⁵⁵.

37. No obstante, aún no se ha llegado a un acuerdo acerca de la amplitud de esos derechos y el momento en que se originan⁵⁶. Si bien la legislación ha sido clara durante cierto tiempo en cuanto a que los acreedores tienen derecho a que se les contemple en virtud de ciertas obligaciones fiduciarias de los directores cuando la empresa cae en la insolvencia⁵⁷, una sentencia de 1991 creó incertidumbre acerca del contenido y el momento en que surgen esos derechos al sostener que “al menos cuando una empresa esté operando en el período cercano a la insolvencia, una junta directiva no es meramente el agente de quienes asumen el riesgo residual, sino que está obligada frente a la empresa”⁵⁸. Una decisión más reciente aclaró que los acreedores de una empresa no tenían derecho a presentar demandas fiduciarias directas contra la empresa independientemente de su solvencia, pero sostuvo que una vez que se había producido la insolvencia, los acreedores de la empresa podían

⁵⁰ Al igual que en el caso de la sección sobre los Estados Unidos de América en INSOL, Directors in the Twilight Zone III (nota 1 *supra*, en 697), la presente sección se centrará en el derecho de Delaware, como jurisdicción en la que se constituyen muchas sociedades, y en el derecho federal (para las cuestiones que se resuelven en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos, y no en los tribunales estatales).

⁵¹ Véase, por ejemplo, *N. Am. Catholic Educ. Programming Foundation, Inc. c. Gheewalla*, 930 A.2d 92, 99 (Del. 2007).

⁵² J. Haskell Murray, “‘Latchkey corporations’: Fiduciary duties in wholly owned, financially troubled subsidiaries” (2011) 36 Delaware Journal of Corporate Law, pág. 584; *Geyer c. Ingersoll Publications Co.*, 621 A.2d 784, 787 (Del.Ch. 1992); e *In re Netzel*, 442 B.R. 896, 899 (Bankr. N.D. Ill. 2011).

⁵³ *Geyer c. Ingersoll*, *ibid* en 787 e *In re Netzel*, *ibid* en 899.

⁵⁴ Murray, “Latchkey corporations”, nota 52 *supra* en 587.

⁵⁵ *Ibid* en 588 y *N. Am. Catholic Educ. Programming Foundation, Inc. c. Gheewalla*, nota 51 *supra* en 101.

⁵⁶ Véase, en general, INSOL, Directors in the Twilight Zone III, nota 1 *supra* en págs. 704 a 706.

⁵⁷ *Geyer c. Ingersoll Publications Co.*, nota 52 *supra* en 787.

⁵⁸ *Crédit Lyonnais Bank Nederland, N.V. c. Pathé Communications Corp.* 1991 WL 277613 (Del. Ch., 30 de diciembre de 1991).

incoar demandas derivadas en representación de la empresa contra los directores por incumplimiento del deber fiduciario⁵⁹. Desafortunadamente, la decisión no abordó la cuestión de si los acreedores tienen un derecho similar a presentar demandas derivadas por incumplimiento del deber fiduciario en el período cercano a la insolvencia, ni tampoco ha habido ningún caso hasta la fecha del que se pudieran extraer directrices para cuando una empresa está entrando en la “proximidad de la insolvencia”. Además, otros estados otorgan a los acreedores capacidad legal para incoar una demanda por incumplimiento de los deberes fiduciarios cuando la filial está en la “zona” o en la “proximidad” de la insolvencia⁶⁰, y no limitan esa capacidad legal a demandas derivadas en nombre de la filial.

38. En el contexto de un grupo de empresas, se ha sostenido que los directores de filiales solventes de propiedad total⁶¹ están obligados a gestionar los asuntos de la filial únicamente en el mejor interés de la empresa matriz y sus accionistas⁶². Otra jurisprudencia, a veces más reciente, ha limitado la aplicación de ese caso, y ha sostenido que los directores de una filial solvente de propiedad total tienen obligaciones fiduciarias para con la empresa filial y también para con su único accionista, la empresa matriz⁶³.

39. No obstante, el estado actual de la legislación en lo que respecta a las obligaciones de los directores en el seno de grupos de empresas en el período cercano a la insolvencia es bastante incierto. Como se observó anteriormente en el párrafo 37, los acreedores pueden incoar demandas derivadas en nombre de una empresa insolvente por los daños que le han causado sus directores o su accionista con participación dominante⁶⁴. Además, como se observó anteriormente en la nota 61, los directores de las filiales pueden verse expuestos a demandas por incumplimiento del deber de lealtad o a demandas contra el “director interesado”

⁵⁹ *N. Am. Catholic Educ. Programming Foundation, Inc. c. Gheewalla*, nota 51 *supra* en 101 e *In re Netzel*, nota 52 *supra* en 901.

⁶⁰ Murray, “Latchkey corporations”, nota 52 *supra* en 588-591 y 608; *Carrieri c. Jobs.com Inc.*, 393 F.3d 508, 534 n.24; *In re James River Coal Co.*, 360 B.R. 139, 170 (Bankr. E.D. Va. 2007).

⁶¹ Fuera del contexto de la filial de propiedad total, se ha dicho que el conflicto entre las obligaciones debidas a la empresa controlada y a la matriz es de escasa importancia práctica, dado que las decisiones de los directores están por lo general protegidas por las disposiciones de la regla del criterio comercial y la carta exculpatoria. Véase Murray, “Latchkey corporations”, nota 52 *supra* en la pág. 580 y *Orman c. Cullman*, 794 A.2d 5, 22 (Del. Ch. 2002) (observando que la presunción de la regla del criterio comercial protege mucho las decisiones de los directores, pero puede refutarse en determinadas circunstancias, por ejemplo, si los directores estaban “interesados” en el resultado de la operación impugnada) y Del. Code Ann tit. 8 § 102 b) 7) (que permite que las empresas eliminen la responsabilidad por daños debido al incumplimiento del deber de diligencia salvo en el caso de incumplimiento del “deber del director de lealtad a la empresa o a sus accionistas”).

⁶² *Anadarko Petroleum Corp. c. Panhalde Eastern Corp.* 545 A.2d 1171 (Tribunal Supremo de Delaware, 1988) y *Trenwick Am. Litigation Trust c. Ernst & Young, L.L.P.*, 906 A.2d 168, 196 n.75 (Del. Ch. 2006).

⁶³ *First American Corporation c. Al-Nahyan*, 17 F Supp. 2d 26 (DC, 1998) e *In re Touch American Holdings, Inc.*, 401 BR 107, 129 (Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, 2009). No obstante, la realidad es que en la práctica, cuando una filial de propiedad total es solvente, solo la matriz tiene capacidad legal para presentar una típica demanda por incumplimiento de obligaciones fiduciarias: Murray, “Latchkey corporations”, nota 52 *supra* en 597.

⁶⁴ Murray, “Latchkey corporations”, nota 52 *supra* en 603.

que pueden incoar como demandas derivadas los acreedores de la filial. En el período cercano a la insolvencia, los directores de filiales de propiedad total que simplemente acatan los deseos de la empresa matriz y aprueban negocios que tienen como resultado la insolvencia de la filial podrían tener que responder por incumplimiento del deber de lealtad o ser objeto de demandas contra el “director interesado”⁶⁵. Por lo tanto, el estado actual de la legislación puede alentar a los directores de filiales de propiedad total en el período cercano a la insolvencia a concentrarse en los intereses de los acreedores de la filial en lugar de gestionarla teniendo presente el mejor interés de la empresa matriz y de la filial, aunque no exista una obligación fiduciaria específica frente a los acreedores de la filial porque esa filial aún no ha caído en la insolvencia. Es así que en el período cercano a la insolvencia, los directores de filiales de propiedad total al parecer deben actuar teniendo presente el mejor interés de la filial, lo que puede incluir los intereses de la matriz accionista única, y también puede incluir los intereses de los acreedores de la filial⁶⁶.

III. Cuestiones que deben examinarse

40. A partir del análisis que antecede, cabe observar que la cuestión de las obligaciones de los directores en la zona de insolvencia en el contexto de grupos de empresas no parece haber sido tratada en forma clara ni tampoco ampliamente en la legislación nacional. El concepto de grupos de empresas se ha examinado y desarrollado en muchas jurisdicciones, pero hay cuestiones que siguen siendo algo confusas en lo que respecta a las obligaciones de los directores en esas situaciones.

41. A la luz de la creciente importancia de los grupos de empresas en las actividades comerciales modernas a nivel mundial, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la posibilidad de ofrecer alguna orientación en este ámbito mediante la inclusión de la cuestión de las obligaciones de los directores de miembros de grupos de empresas durante el período cercano a la insolvencia en su labor actual. De ser así, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la mejor manera de incluir este tema. En sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar también si sería útil recordar el enfoque adoptado con respecto a las disposiciones en materia de impugnación de las operaciones efectuadas entre empresas de un mismo grupo que figuran en la recomendación 217 de la tercera parte de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia (Trato otorgable a los grupos de empresas en situaciones de insolvencia).

⁶⁵ *Ibid* en 605.

⁶⁶ *Ibid* en 607-608.

**K. Nota de la Secretaría sobre la Ley Modelo de la CNUDMI sobre
la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial**

(A/CN.9/778)

[Original: inglés]

I. Introducción

1. En su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión finalizó y aprobó la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial¹ y pidió a la Secretaría que estableciera un mecanismo para actualizar continuamente el texto con la misma flexibilidad con que se elaboró, y garantizando que se mantuviera su tono neutro y que siguiera cumpliendo la finalidad enunciada en él².
2. La Secretaría creó una junta de expertos para que la asesorara en la actualización de la Perspectiva Judicial, a fin de tener en cuenta la jurisprudencia reciente de interpretación de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza y de reflejar las revisiones que se estaban preparando de la Guía para la incorporación de la Ley Modelo al derecho interno.
3. En el texto que figura más adelante se recogen los párrafos de la Perspectiva Judicial que han sido objeto de actualización para reflejar la jurisprudencia más reciente, así como las revisiones de la Guía para la incorporación de la Ley Modelo al derecho interno propuestas por el Grupo de Trabajo V (véase A/CN.9/WG.V/WP.112), con miras a su examen por la Comisión en su 46º período de sesiones, junto con las modificaciones propuestas en el 43º período de sesiones del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) en abril de 2013 (véase A/CN.9/766). Los párrafos que no van a ser actualizados (y que, por tanto, siguen siendo los mismos que figuran en la versión publicada del texto) no han sido incluidos en el presente documento; en ese caso, esos párrafos se indican mediante el signo [...]. El Anexo I incluye únicamente los resúmenes de nuevos casos que se han de agregar al texto; la lista de casos indica todos los casos que serán incluidos en el anexo completo.

¹ A la fecha del presente documento, el texto se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency/2011Judicial_Perspective.html.

² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 198.*

II. La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial

Índice

I.	Introducción	
A.	Finalidad y alcance	
B.	Glosario	
II.	Antecedentes	
A.	Alcance y aplicación de la Ley Modelo de la CNUDMI	
B.	La perspectiva de un juez	
C.	Finalidad de la Ley Modelo de la CNUDMI	
III.	Interpretación y aplicación de la Ley Modelo de la CNUDMI	
A.	El principio del “acceso”	
B.	El principio del “reconocimiento”	
C.	El proceso de reconocimiento de un procedimiento extranjero	
D.	Medidas previstas	
E.	Cooperación y coordinación	
Anexos		
I.	Resúmenes de casos	
II.	Decisión de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y resolución 66/9 de la Asamblea General	

Prefacio

Párrs. 1 a 3 [...].

La Perspectiva Judicial fue actualizada en 2013 para reflejar las revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo, adoptadas por la Comisión en 2013 como Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo, y para incluir la jurisprudencia reciente de aplicación e interpretación de la Ley Modelo. El Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia), en su 43º período de sesiones (abril de 2013), y el Décimo Coloquio Judicial Multinacional, celebrado en La Haya en mayo de 2013, tomaron nota de las actualizaciones del texto publicado de *La Perspectiva Judicial*, antes de que la Comisión los examinara en el año en curso.

I. Introducción

A. Finalidad y alcance

1. En el presente texto se examina la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza desde la perspectiva de un juez. Habida cuenta de que algunos Estados promulgantes han enmendado la Ley Modelo adoptándola a las circunstancias del país, cabría seguir distintos enfoques si un juez llega a la conclusión de que es preciso omitir o modificar un determinado artículo del texto promulgado³. El presente texto se basa en la Ley Modelo aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1997 y en la Guía para la incorporación al derecho interno que acompaña la Ley⁴. La Guía para la incorporación al derecho interno ha sido sometida a revisión a fin de incluir las orientaciones adicionales impartidas con respecto a la interpretación y aplicación de determinados aspectos de la Ley Modelo relativos al “centro de los principales intereses”, a la luz de la nueva jurisprudencia de interpretación de la Ley Modelo en los Estados que han promulgado legislación basada en ella. La Comisión aprobó las revisiones en 2013 como “Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza”.

2. [...]

3. [...]

4. [...]

B. Glosario

1. Términos, conceptos y explicaciones

5. [...]

2. Material de referencia

a) Remisiones a casos

6. [...]

b) Remisiones a textos

7. [...]

a) [...]

b) “La Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación”: la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza, revisada en 2013;

³ En el presente texto no se remite a las distintas adaptaciones de la Ley Modelo que han hecho algunos Estados promulgantes ni se emiten opiniones al respecto.

⁴ Resolución 52/158 de la Asamblea General.

c) “La Guía Legislativa de la CNUDMI”: La Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia (2004), comprendida la parte tercera adoptada en 2010;

d) a g) [...]

II. Antecedentes

A. Alcance y aplicación de la Ley Modelo de la CNUDMI

8. En diciembre de 1997, la Asamblea General refrendó la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza, elaborada y adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). La Ley Modelo iba acompañada de una Guía para la incorporación al derecho interno que ofrecía información explicativa y de antecedentes para ayudar a los encargados de preparar la legislación necesaria para aplicar la Ley Modelo y a los jueces y demás responsables de su aplicación e interpretación. Como ya se señaló, la Guía para la incorporación al derecho interno ha sido revisada a fin de incluir las orientaciones complementarias impartidas con respecto a la interpretación y aplicación de determinados aspectos de la Ley Modelo relativos al “centro de los principales intereses”, y la Comisión la aprobó en 2013 como “Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza”.

9. Revíse la última oración de modo que diga: “A fines de abril de 2013, 20 Estados y territorios habían promulgado legislación basada en la Ley Modelo⁵”.

10 a 15. [...]

B. La perspectiva de un juez

16. Si bien la Ley Modelo de la CNUDMI pone de relieve la conveniencia de adoptar un enfoque uniforme de su interpretación que se base en sus orígenes internacionales⁶, es probable que el derecho interno de la mayoría de los Estados exija una interpretación conforme a la legislación del respectivo Estado, a menos

⁵ Australia (2008), Canadá (2005), Colombia (2006), Eritrea (1998), Eslovenia (2007), Estados Unidos de América (2005), Gran Bretaña (2006), Grecia (2010), Islas Vírgenes Británicas (territorio de ultramar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (2003), Japón (2000), Mauricio (2009), México (2000), Montenegro (2002), Nueva Zelandia (2006), Polonia (2003), República de Corea (2006), Rumania (2002), Serbia (2004), Sudáfrica (2000) y Uganda (2011). El año de promulgación indicado es el año en que el órgano legislativo correspondiente aprobó la legislación, según se comunicó a la Secretaría de la CNUDMI; no se indica la fecha de entrada en vigor de esa legislación, puesto que, como los procedimientos pertinentes difieren de un Estado a otro, la entrada en vigor podría producirse con cierta posterioridad a la promulgación.

⁶ En los Estados que incorporen a su derecho interno la Ley Modelo, sus disposiciones deberán interpretarse teniendo en cuenta “su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe” (Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 8).

que el Estado promulgante haya hecho suyo el criterio “internacional” en su propia legislación⁷. En cualquier caso, es probable que todo tribunal que tenga en cuenta la legislación basada en la Ley Modelo encuentre que la jurisprudencia internacional lo ayudará en su interpretación.

17 a 23. [...]

24. Agregar la siguiente oración al final del párrafo: “El Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia), en su 43º período de sesiones (abril de 2013), y el Décimo Coloquio Judicial Multinacional, celebrado en La Haya en mayo de 2013, tomaron nota de las revisiones del texto publicado, antes de que la Comisión las examinara en el año en curso.”

C. Finalidad de la Ley Modelo de la CNUDMI

25. [...]

26. Como ya se ha mencionado, la Ley Modelo respeta las diferencias entre las leyes procesales nacionales y no pretende lograr una unificación sustantiva de los regímenes de la insolvencia. Constituye, más bien, un marco de cooperación entre jurisdicciones, ofreciendo soluciones que pueden contribuir a resolver problemas mediante métodos aparentemente sencillos pero importantes, consistentes, por ejemplo en:

a) a f) [...]

g) Establecer reglas de coordinación entre las medidas cautelares otorgadas en el Estado promulgante para prestar asistencia a dos o más procedimientos de insolvencia entablados, respecto del mismo deudor, en distintos Estados.

27 y 28. [...]

III. Interpretación y aplicación de la Ley Modelo de la CNUDMI

A. El principio del “acceso”

29 a 34. [...]

35. La Ley Modelo de la CNUDMI prevé que un “representante extranjero” pueda estar designado a título provisional, pero en la definición no entra el caso de un representante cuyo mandato aún no haya entrado en vigor, por ejemplo, debido a la suspensión de una orden de nombramiento del representante de la insolvencia a raíz de una apelación⁸. Cuando se produzca un cambio de la condición jurídica del

⁷ Efectivamente, la propia Ley Modelo de la CNUDMI especifica que, en caso de conflicto entre la Ley Modelo y un tratado o acuerdo en el que el Estado promulgante sea parte, las disposiciones de ese tratado o acuerdo prevalecerán sobre las disposiciones de la Ley Modelo (artículo 3) y los párrafos 76 a 78 de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación.

⁸ Véase la definición de “representante extranjero” en el artículo 2 d) de la Ley Modelo de la CNUDMI. Un representante extranjero cuyo nombramiento se haya iniciado pero cuya situación jurídica pueda, no obstante, ser objeto de nuevo examen por el tribunal que lo designó, se consideraría como representante extranjero a los efectos del artículo 2 (véase *Lightsquared*,

representante extranjero con posterioridad a su nombramiento, la cuestión se resolvería con arreglo al artículo 18 a). Un criterio para determinar si una persona puede considerarse “representante extranjero” consiste en examinar si se satisfacen los requisitos de la definición de “procedimiento extranjero” antes de determinar si el solicitante ha sido autorizado⁹ a administrar una organización o liquidación de los bienes o negocios del deudor o a actuar como representante del procedimiento extranjero.

36. Conforme a ese enfoque, el juez debería asegurarse de que:

a) El “procedimiento extranjero” respecto del cual se solicita el reconocimiento es un procedimiento judicial o administrativo (comprendido un procedimiento provisional) que se desarrolla en un Estado extranjero¹⁰.

b) a e) [...]

37. [...]

B. El principio del “reconocimiento”

1. Observación introductoria

38 y 39. [...]

2. Requisitos probatorios

40. [...]

3. Poderes sustantivos para reconocer un procedimiento extranjero

41 a 45. [...]

4. Reciprocidad

46. Agregar “y Uganda” a la nota de este párrafo.

5. La excepción basada en el “orden público”

47. El tribunal ante el que se recurra puede reservarse el derecho a negarse a adoptar cualquiera de las medidas contempladas en la Ley Modelo, incluido el derecho a denegar el reconocimiento de un procedimiento extranjero o el otorgamiento de medidas solicitadas, si la adopción de esas medidas resultara “manifiestamente contraria” al orden público del estado en cuyo territorio se encontrara el tribunal. El concepto de “orden público” está definido en el derecho interno y puede variar de un Estado a otro, razón por la cual la Ley Modelo no contiene una definición uniforme de “orden público”.

párrs. 19 y 20). Sin embargo, en caso de que, a raíz de ese nuevo examen hubiera de modificarse la condición jurídica del representante extranjero, el tribunal ante el que se recurra tendría que revisar la cuestión a la luz del artículo 18 de la Ley Modelo.

⁹ A los efectos del artículo 2 d) de la Ley Modelo de la CNUDMI.

¹⁰ Véase el examen de las órdenes provisionales y finales en *Gerova* (págs. 12 y 18), nota del párrafo 54 b) del presente documento.

48. En algunos Estados el concepto de “orden público”, puede interpretarse con criterios amplios, asimilándose en principio a cualquier regla imperativa de derecho interno. No obstante, en muchos Estados la excepción de orden público se considera limitada a principios fundamentales del derecho, en particular las garantías constitucionales. En esos Estados la excepción de orden público se invocaría para denegar la aplicación de una ley extranjera o el reconocimiento de una sentencia o de un laudo arbitral extranjeros, únicamente cuando tal aplicación o tal reconocimiento vulneraran esos principios fundamentales. El concepto de principio fundamental se rige por la legislación de orden constitucional o de derecho estatutario del Estado en que se encuentra el tribunal. En el caso *Ephedra* se consideró que “no era manifiestamente contraria a los principios de orden público de los Estados Unidos” la imposibilidad de celebrar un juicio con jurado en el Canadá sobre ciertas cuestiones que se habían de resolver en el procedimiento canadiense, en una situación en la que existía un derecho constitucional a un juicio de esa naturaleza en los Estados Unidos. El tribunal estadounidense dictaminó, en el recurso de apelación, que la expresión “manifiestamente contraria al orden público” daba pie a una excepción muy restringida “que solo debe invocarse en circunstancias excepcionales concernientes a asuntos de importancia fundamental para el Estado promulgante”. El tribunal llegó a la conclusión de que, no obstante la importancia que tiene en los Estados Unidos el derecho constitucional a un juicio con jurado, las normas procesales aplicables permitían claramente a los demandantes acogerse a un procedimiento equitativo e imparcial (aunque no hubiese un juicio con jurado) y de que la disposición del ordenamiento interno de los Estados Unidos equivalente al artículo 6 no imponía ningún otro requisito¹¹.

49 a 51. [...]

51A. Además del caso *Ephedra*, en varios casos se ha tenido en cuenta también la excepción basada en el orden público. En el caso *Gold & Honey*, un tribunal estadounidense denegó el reconocimiento de un procedimiento israelí por varios motivos, entre otros los relacionados con el orden público. En ese caso, tras haberse iniciado en los Estados Unidos un procedimiento de insolvencia y tras haberse dictado la paralización automática, se recibió una orden de administración judicial dictada en Israel para la empresa deudora. El juez estadounidense se negó a reconocer el procedimiento de administración judicial con el argumento de que la orden dictada en Israel no solo no constituía un procedimiento colectivo o en el que los bienes y negocios del deudor estuviesen sujetos al control o la supervisión del tribunal, sino porque también significaría “recompensar y legitimar [la] violación tanto de la paralización automática como [de las órdenes posteriores del tribunal] referentes a la paralización”¹². Dado que el reconocimiento “obstaculizaría gravemente la capacidad de los tribunales de quiebras de los Estados Unidos de aplicar dos de las políticas y propósitos más fundamentales de la paralización automática, a saber, impedir que un acreedor obtenga un beneficio frente a otros acreedores y prever la distribución eficaz y ordenada de los bienes del deudor entre todos los acreedores teniendo en cuenta su respectiva prelación”¹³, el juez estadounidense consideró que se había satisfecho el alto nivel de exigencia requerido para fundamentar una excepción por razones de orden público.

¹¹ *Ephedra*, pág. 349.

¹² *Gold & Honey*, pág. 371.

¹³ *Ibid.*, pág. 372.

51B. En el caso *Toft*, un tribunal estadounidense denegó al representante extranjero de un procedimiento de insolvencia entablado en Alemania el derecho a interceptar el correo postal y electrónico del deudor en los Estados Unidos. El juez estimó que dicha orden recaía dentro de la excepción por motivos de orden público porque rebasaba los límites tradicionales de las facultades de un fideicomisario con arreglo al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, constituía una medida que estaba prohibida por ley en los Estados Unidos y podría exponer a juicio penal a quienes se valieran de ella. La solicitud de una medida de esa índole a instancia de parte era también contraria al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos. En Inglaterra, en cambio, se había reconocido y ejecutado una orden similar argumentando que a) la medida otorgada en Alemania no contravenía el orden público inglés puesto que, en virtud del derecho inglés, el tribunal podía dictar la orden de remitir el correo a otro destinatario similar a la orden dictada en Alemania, y b) no habría lugar a la falta de equidad en el procedimiento al otorgar la medida de excepción a instancia de parte, porque el deudor había podido impugnar la orden de interceptación del correo en el procedimiento alemán, y el tribunal alemán había desestimado esa impugnación¹⁴.

6. Procedimientos extranjeros “principales” y “no principales”

52. [...]

7. Modificación o revocación de una orden de reconocimiento

53. Es posible que el tribunal ante el que se recurra revise su decisión de reconocer un procedimiento extranjero como procedimiento “principal” o como procedimiento “no principal” cuando se demuestre “la ausencia parcial o total de los motivos por los que se otorgó” la orden de reconocimiento¹⁵.

54. Las circunstancias en las que cabría modificar o revocar una decisión de reconocimiento, son, por ejemplo, las siguientes:

a) [...]

b) [...]. Al final del párrafo agréguese una nota de pie de página, cuyo texto diga lo siguiente: “En el caso *Gero*, algunos acreedores arguyeron que no se deberían reconocer los procedimientos extranjeros en los Estados Unidos en vista de que la orden de iniciarlos era objeto de apelación. El tribunal estadounidense estimó que en las disposiciones pertinentes del código de los Estados Unidos (11 USC § 1517, 1515) [artículo 17 o artículo 15, a) de la Ley Modelo] no se estipulaba que la decisión debería ser definitiva ni ser objeto de apelación. El tribunal observó que la orden del tribunal extranjero bastaba para permitir a los representantes extranjeros asumir sus funciones y que en caso de que la orden fuese revocada en apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 los representantes extranjeros deberían informar sin demora al tribunal (pág. 12)”.

c) Cuando se hayan producido cambios en la naturaleza del procedimiento extranjero reconocido, por ejemplo, cuando un procedimiento de reorganización se haya transformado en un procedimiento de liquidación, o en el nombramiento del representante extranjero;

d) [...]

¹⁴ Orden del Tribunal Superior, 16 de febrero de 2011.

¹⁵ *Ibid.*, art. 17, párr. 4.

55. [...]

C. El proceso de reconocimiento de un procedimiento extranjero

1. Introducción

56. [...]

a) Un procedimiento judicial o administrativo en un Estado extranjero;

b) a c) [...]

57 y 58. [...]

59. Para determinar si un procedimiento extranjero (contra una empresa deudora) se debe calificar como procedimiento “principal”, lo fundamental es establecer si se sigue “en un Estado donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses”¹⁶. De tratarse de una persona física, se presume que el “centro de sus principales intereses” es la “residencia habitual” de esa persona. En el caso *Re Stojevic*¹⁷ el tribunal inglés consideró que, fundamentalmente, la residencia habitual de una persona es su hogar permanente establecido, donde vive con su cónyuge y su familia hasta que los miembros más jóvenes de la familia, una vez adultos, abandonan el hogar, y el lugar al que regresa después de sus viajes de trabajo a otros sitios o al extranjero. También observó que una persona podría tener otra residencia, llamada residencia ordinaria, que es un lugar donde vive, sin que sea su domicilio permanente establecido, y el lugar en el que vive cuando se encuentra fuera del hogar por sus actividades laborales o en vacaciones con su cónyuge y su familia. Según la naturaleza de su trabajo, una persona puede vivir fuera de su domicilio permanente establecido durante más días durante un año de los que vive con su cónyuge y su familia. En el caso *Williams c. Simpson (No. 5)*, el tribunal neozelandés estimó que la determinación del lugar de la residencia habitual se basaría principalmente en los hechos propios de cada caso. Señaló que se tendrían en cuenta factores como el objetivo establecido, la duración real y prevista de la permanencia en un Estado, el motivo de la estancia, la intensidad de los lazos con ese Estado o con cualquier otro Estado (tanto en el pasado como en el presente), el grado de asimilación en el Estado (incluidos los arreglos de vivienda y escolarización) y la integración cultural, social y económica”¹⁸. Aunque el deudor había desarrollado actividades empresariales en Inglaterra, donde vivía ocasionalmente, y tenía pasaporte tanto del Reino Unido como de Nueva Zelandia, el tribunal dictaminó que las pruebas presentadas eran insuficientes para refutar la presunción y que la residencia habitual del deudor se encontraba en Nueva Zelandia.

60 a 63. [...]

64. Algunos de los casos en que se consideró el significado de “procedimiento extranjero”, “procedimiento extranjero principal” y “procedimiento extranjero no principal” afectaban a miembros de grupos de empresas. A los efectos de la Ley Modelo, el interés se centra en las entidades individuales y, por consiguiente, en todos y cada uno de los miembros de un grupo empresarial como entidad jurídica

¹⁶ Véase el análisis hecho en los párrafos 75 a 110.

¹⁷ [2007] BPIR 141, párr. 58 y siguientes.

¹⁸ Párr. 42, en que se cita el caso *Basingstoke c. Groot* [2007] NZFLR 363 (CA).

separada¹⁹. Puede suceder que el centro de los principales intereses de cada empresa del grupo pertenezca a la misma jurisdicción, en cuyo caso la insolvencia de esas empresas se puede llevar a cabo en una sola jurisdicción, pero no cabe considerar el centro de los principales intereses del grupo de empresas como tal en el marco de la Ley Modelo.

65. [...]

2. Elementos de la definición de “procedimiento extranjero”

65A. En los párrafos siguientes se examinan las diversas características requeridas de un “procedimiento extranjero” con arreglo al artículo 2. Si bien se examinan por separado, esas características son acumulativas, y el artículo 2 a) debería considerarse como un todo. Al examinar la solicitud de reconocimiento se determinaría si un procedimiento extranjero posee o poseía esas características.

a) “Procedimiento colectivo, ya sea judicial o administrativo”

66. La Ley Modelo de la CNUDMI se elaboró de forma que solo fuera aplicable en determinados tipos de procedimientos de insolvencia. Las revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo indican que la idea de un procedimiento de insolvencia “colectivo” se basa en la conveniencia de llegar a una solución coordinada y global para todas las partes interesadas en un procedimiento de insolvencia. La Ley Modelo no debe entenderse como un mero mecanismo de cobro para un determinado acreedor o grupo de acreedores que puedan haber entablado un procedimiento en otro Estado con el fin de cobrar sus créditos ni como un instrumento encaminado a acumular bienes en un procedimiento de liquidación²⁰ o de rehabilitación que no prevea también disposiciones para atender las reclamaciones de los acreedores. La Ley Modelo puede ser un instrumento apropiado para cierta clase de acciones que tengan fines de reglamentación, por ejemplo la administración judicial de entidades sujetas a reglamentación pública como las compañías de seguros o las empresas de corretaje, siempre y cuando el procedimiento sea colectivo en el sentido en que se emplea ese término en la Ley Modelo. Para que un procedimiento sea colectivo, también debe reunir los demás elementos de la definición, entre ellos que tenga como fin la liquidación o la reorganización (véase párrs. ...).

66A. Al evaluar si un determinado procedimiento es colectivo a efectos de la Ley Modelo, una de las consideraciones fundamentales es determinar si en el procedimiento se tienen en cuenta prácticamente todos los bienes y las deudas del deudor, sin perjuicio de las prioridades y excepciones legislativas del país ni de la exclusión de determinados derechos de los acreedores garantizados en su ordenamiento jurídico. Sin embargo, no se puede considerar que un procedimiento no es colectivo únicamente por el hecho de que no afecte a los derechos de una clase particular de acreedores. Un ejemplo sería el procedimiento de insolvencia en que se excluyen los bienes gravados de la masa de la insolvencia, de tal manera que no les afecte la apertura del procedimiento y se permita a los acreedores garantizados

¹⁹ Este punto lo pone de relieve el tribunal canadiense en el caso *Lightsquared*, párr. 29; véase también el caso *Eurofood*, párr. 37 (resuelto en virtud del Reglamento del Consejo Europeo).

²⁰ La “liquidación” es un procedimiento por el cual se pone fin a la existencia de una empresa y de sus negocios.

hacer valer sus derechos al margen del régimen de la insolvencia. Otra manera de tratar a los acreedores en un procedimiento colectivo a los efectos del artículo 2 es otorgar a los acreedores que se vean perjudicados por el procedimiento el derecho (aunque no necesariamente la obligación) a presentar sus créditos con miras a que se adopte una determinación, a recibir una parte equitativa en la distribución que se haga, o a la satisfacción de esos créditos, a participar en el procedimiento y a recibir una notificación a fin de facilitar esa participación²¹.

67 a 69. [...]

70. En otro caso, el caso *Stanford International Bank*, el tribunal inglés dictaminó que un mandamiento de administración judicial dictado por un tribunal estadounidense no era un procedimiento colectivo con arreglo a una ley relativa a la insolvencia. El tribunal ante el que se recurrió dictaminó que el mandamiento se había otorgado después de la intervención de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) para “impedir un fraude masivo”. El objetivo del mandamiento era impedir que los inversores sufrieran una pérdida, y no reorganizar la sociedad o realizar bienes en beneficio de todos los acreedores²². Esa opinión fue corroborada en apelación, en gran medida por los mismos motivos aducidos por el tribunal inferior inglés²³. En otra decisión referente al caso *Stanford International Bank*, un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos hizo notar el lenguaje utilizado en otras opiniones de tribunales estadounidenses en las que se había contrapuesto un procedimiento colectivo a un mandamiento de administración judicial y se llegaba a la conclusión de que este último no constituía un procedimiento colectivo²⁴ basándose en que se trataba de un recurso iniciado a instancias de un único acreedor garantizado y para su beneficio. El tribunal estadounidense incluso llegó a la conclusión de que el mandamiento de administración judicial previsto en el caso *Stanford* no constituía un mandamiento de ese tipo ya que había sido dictado “a solicitud de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos en beneficio de todos los acreedores e inversores que habían sido víctimas de entidades de Stanford”. El tribunal llegó a la conclusión de que aunque el caso que tenía ante sí no requería que dirimiera la cuestión, consideraría, con todo, que el mandamiento de administración judicial constituía un procedimiento colectivo²⁵.

70A. En *ABC Learning Centres*, el tribunal estadounidense estimó que diversas disposiciones de la ley australiana apuntaban a la naturaleza colectiva del procedimiento de liquidación que era objeto de la solicitud de reconocimiento. Entre

²¹ En el caso *Ashapura Minechem*, el tribunal estadounidense estimó que aunque la legislación india con arreglo a la cual se había entablado el procedimiento extranjero no preveía un mecanismo formal para la participación de acreedores no asegurados, en la práctica esos acreedores tenían voz en el procedimiento (a discreción de la Junta de Reconstrucción Industrial y Financiera que administraba la legislación pertinente), podían ser parte en las distribuciones en virtud de un arreglo con los acreedores y gozaban del derecho de apelar contra determinaciones contrarias que adoptara la Junta y hacer que dichas apelaciones fuesen escuchadas en el sistema judicial de la India. El tribunal llegó a la conclusión de que la posibilidad de una revisión por un tribunal de apelación y el derecho de los acreedores a participar ante la Junta demostraban que el procedimiento era colectivo (págs. 5 y 6).

²² *Stanford International Bank*, párrs. 73 y 84.

²³ *Stanford International Bank* (en apelación), párrs. 26 y 27.

²⁴ Esos casos se citan en *Betcorp*, pág. 281.

²⁵ *Stanford International Bank*, Tribunal del Distrito del Norte de Texas, 2012, pág. 19, nota 20.

esas disposiciones cabía mencionar la obligación del liquidador de tener en cuenta los derechos de los acreedores al distribuir los activos del deudor; que, a reserva de determinadas prioridades y otras consideraciones, las deudas y reclamaciones se equiparaban y deberían pagarse por prorratio; que se debía notificar debidamente a todos los acreedores con respecto al procedimiento de insolvencia y las reuniones de acreedores conexas; que la decisión de iniciar ese procedimiento contara con el respaldo de la mayoría de los acreedores tanto por su número como por el monto de la suma que se les adeudaba; que en el comité de acreedores establecido según lo estipulado en la ley australiana habían participado representantes de diversos tipos de acreedores; y que los acreedores tenían el derecho a solicitar la revisión por el tribunal. Hubo acuerdo en que los procedimientos de administración judicial que tuvieran lugar simultáneamente con los de liquidación, situación contemplada en la ley australiana, no constituían un procedimiento colectivo ya que, por su concepción, tenían por objeto beneficiar a los acreedores garantizados que hubiesen iniciado esa acción²⁶.

b) “Conforme a una ley relativa a la insolvencia”

70B. La Ley Modelo incluye el requisito de que el procedimiento extranjero se siga “con arreglo a una norma relativa a la insolvencia” para reconocer el hecho de que la liquidación y la reorganización pueden realizarse en virtud de una legislación que no esté comprendida en el régimen de la insolvencia (por ejemplo, el derecho de sociedades), pero que no obstante regule o aborde cuestiones relacionadas con la insolvencia o situaciones de graves apuros financieros. Se trataba de hallar una descripción lo suficientemente amplia como para abarcar una gama de normas de insolvencia independientemente del tipo de instrumento legislativo en el que estuvieran incluidas²⁷ y de si este contenía o no normas relativas exclusivamente a la insolvencia.

70C. Los tribunales han examinado ese aspecto del artículo 2 a) en varios casos relativos a procedimientos de liquidación voluntarios. En el caso *Stanford International Bank*, el tribunal inglés de primera instancia llegó a la conclusión de que la liquidación de una empresa de Antigua, ordenada por el tribunal de Antigua basándose en que era justo y equitativo proceder a liquidarla, “se ajustaba a una ley relativa a la insolvencia”. Aunque el motivo de la liquidación se limitaba a una acción de conducta reglamentaria indebidamente de acuerdo con la legislación aplicable, la insolvencia de la empresa era un factor pertinente a la facultad discrecional del tribunal de Antigua de dictar la orden. La decisión fue corroborada en el recurso de apelación, y el tribunal de apelaciones inglés observó que puesto que la ley de Antigua preveía la liquidación de sociedades por motivos justos y equitativos, entre los que se contaba la insolvencia, así como el incumplimiento de requisitos reglamentarios, la decisión se podría calificar como una decisión “con arreglo a una ley relativa a la insolvencia”. En *Betcorp*, el tribunal estadounidense estimó que una liquidación voluntaria iniciada con arreglo al derecho australiano se ajustaba “a una ley relativa a la insolvencia” dado que cuando se tenía en cuenta la naturaleza de la legislación pertinente (la Ley de Sociedades) en su conjunto, se trataba de una ley que regulaba todo el ciclo de vida de una sociedad mercantil

²⁶ *ABC Learning Centres*, en IV.1.c.

²⁷ Documento de las Naciones Unidas A/CN.9/422, párr. 49, que se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/en/commission/sessions/29th.html.

australiana, comprendida su insolvencia. El tribunal estadounidense siguió esa decisión en *ABC Learning Centres*, que también se relacionaba con una liquidación voluntaria de acreedores australianos efectuada con arreglo a la misma ley.

70D. En el caso *Chow Cho Poon*, un tribunal australiano consideró si una liquidación judicial, ordenada por un tribunal de Singapur con el argumento de que era justa y equitativa, era un proceso “con arreglo a una ley relativa a la insolvencia”. El tribunal tuvo en cuenta las decisiones de los casos *Stanford International Bank, Betcorp* y *ABC Learning Centres* y llegó a la conclusión de que esas decisiones apuntaban a una base clara sobre la que se podrían clasificar las disposiciones referentes a esas liquidaciones como “una ley relativa a la insolvencia”. En consecuencia, aun cuando la liquidación de que se trataba fue ordenada por razones de justicia y equidad únicamente y al parecer sin ninguna consideración explícita o implícita de insolvencia, cabía afirmar que se hacía “con arreglo a una ley relativa a la insolvencia”.

70E. Tras el examen y las deliberaciones sobre esta cuestión en el Grupo de Trabajo y en la Comisión, en las revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo se adopta un enfoque diferente de las decisiones antes citadas, y se aclara que no es probable que un procedimiento sencillo para una entidad jurídica solvente que no busque reestructurar sus asuntos financieros sino disolverse como entidad jurídica, se rija por una ley relativa a la insolvencia o a situaciones de graves apuros financieros a los efectos del artículo 2 a). Cuando un tipo de procedimiento se haya abierto con varios fines, entre ellos el de liquidar una entidad solvente, se le aplicará el artículo 2 a) de la Ley Modelo únicamente si el deudor es insolvente o está en una situación de graves apuros financieros.

c) Sujetos al control o a la supervisión del tribunal extranjero

71. La definición de “tribunal extranjero”²⁸ no establece ninguna diferencia entre un procedimiento de organización y un procedimiento de liquidación controlado o supervisado por un órgano judicial o administrativo. Este enfoque se adoptó para asegurarse de que los regímenes jurídicos en los que el control o la supervisión son ejercidos por órganos no judiciales quedasen incluidos en el ámbito de la definición de “procedimiento extranjero”²⁹.

71A. En la Ley Modelo no se definen el grado de control o supervisión necesario para cumplir ese aspecto de la definición ni el momento en que se debe proceder a ese control o esa supervisión. En las revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación se indica que aunque la intención es que el control o la supervisión que exige el apartado a) sea de índole oficial, puede ser más potencial que real. Los procedimientos en que el deudor conserva cierto control

²⁸ Ley Modelo de la CNUDMI, art. 2 e).

²⁹ Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación, párr. 74. En el caso *Ashapura Minechem*, por ejemplo, el procedimiento indio reconocido en los Estados Unidos estaba pendiente ante la Junta de Reconstrucción Industrial y Financiera, organismo administrativo autorizado para ejercer como tribunal administrativo en virtud de la Ley de empresas industriales en dificultades (Disposiciones Especiales), 1985. En el caso *Tradex Swiss AG* (384 BR 34 en 42 (2008)) [CLOUT], caso núm. 791, la Comisión Federal de la Banca Suiza fue considerada un “tribunal extranjero” porque controlaba y supervisaba la liquidación de entidades dedicadas a la intermediación bancaria.

sobre sus bienes, aun cuando haya de actuar bajo la supervisión del tribunal, como en el caso de un deudor en posesión, cumplirían ese requisito. El control o la supervisión puede ejercerlo no solo el tribunal directamente sino también un representante de la insolvencia en el caso, por ejemplo, de que dicho representante esté sujeto al control o la supervisión del tribunal. La mera supervisión de un representante de la insolvencia por una autoridad expedidora de licencias no bastaría.

71B. No se deben excluir los procedimientos en que el tribunal ha ejercido el control o la supervisión pero deja de estar obligado a ello una vez que se presenta la solicitud de reconocimiento. Un ejemplo de esta última situación podrían ser los casos en que haya aprobado un plan de reorganización y, aunque el tribunal no tenga una función continua con respecto a su aplicación, los procedimientos sigan abiertos o pendientes y el tribunal mantenga la jurisdicción hasta que concluya la aplicación.

71C. En el artículo 2 a) se deja en claro que tanto los bienes como los negocios del deudor deben estar sujetos a control o supervisión judicial; no bastaría con que el procedimiento extranjero abarcará solo una cosa o la otra³⁰.

72. Hasta el momento, el concepto de “control o supervisión” ha recibido limitada atención judicial.

73. [suprimido]

74. El tribunal del caso *Betcorp* dictaminó que el procedimiento de liquidación voluntaria iniciado en Australia estaba sometido a la supervisión de una autoridad judicial: los tribunales australianos. Esa opinión se basaba en tres factores: a) la capacidad de los liquidadores y los acreedores en una liquidación voluntaria de pedir la intervención de un tribunal para resolver cualquier cuestión que se plantee durante esa liquidación; b) la jurisdicción general de los tribunales australianos sobre la supervisión de los actos de los liquidadores; y c) la capacidad de cualquier persona “agraviada por cualquier acto, omisión o decisión” de un liquidador de apelar a un tribunal australiano, el cual podrá “confirmar, revocar o modificar el acto o decisión, o corregir la omisión, según proceda”³¹.

74A. En el caso posterior de *ABC Learning Centres* la solicitud de reconocimiento del procedimiento extranjero entablado en Australia fue impugnada por varias razones, entre ellas que el procedimiento de insolvencia extranjero no estaba bajo el control o supervisión de un tribunal extranjero. Sin embargo, el tribunal de los Estados Unidos estimó, basándose en los factores enunciados en *Betcorp*, que, no obstante el hecho de que los tribunales australianos no dirigieran las operaciones cotidianas del deudor y de que la mayoría de los liquidadores continuaban ejerciendo sus obligaciones en gran medida sin participación del tribunal, la ley pertinente asignaba al tribunal australiano diversas funciones de control y supervisión con respecto a procedimientos de liquidación que satisficieran los requisitos del artículo 2 a)³².

d) A los efectos de reorganización o liquidación

³⁰ *Gold & Honey*, pág. 371.

³¹ *Betcorp*, págs. 283 y 284.

³² *ABC Learning Centres*, [cita por completar].

74B. Algunos tipos de procedimiento que tal vez satisfagan algunos elementos de la definición de procedimiento extranjero pueden, no obstante, no ser reconocibles por el hecho de no tener por objeto la reorganización o liquidación. Esos procedimientos pueden adoptar diversas formas, incluso puede tratarse de procedimientos concebidos para evitar la dispersión y el desperdicio de los bienes, y no para liquidar o reorganizar la masa de la insolvencia; de procedimientos para impedir que se cause perjuicios a los inversionistas y no a la totalidad de los acreedores (en cuyo caso es probable que no se trate de un procedimiento correctivo); o de procedimientos en los que los poderes conferidos y los deberes impuestos al representante extranjero sean más limitados que los habituales en los casos de liquidación o reorganización, por ejemplo, el poder que solo permite preservar los bienes.

74C. Entre los tipos de procedimiento que podrían no reconocerse figuran las medidas o arreglos de ajuste financiero, de naturaleza puramente contractual, concertados entre el deudor y alguno de sus acreedores en lo que respecta a determinada deuda cuando las negociaciones no conducen a la apertura de un procedimiento de conformidad con la ley de la insolvencia³³. Esas medidas no cumplirían generalmente el requisito de ser de carácter colectivo ni el relativo al control o la supervisión judicial (véanse párrs. 71 a 74).

3. Procedimiento “principal”: el centro de los principales intereses

a) Introducción

75 y 76. [...]

77. Al comienzo de la tercera oración, suprimanse las palabras “A diferencia de la disposición correspondiente de la Ley Modelo de la CNUDMI”.

78 a 80. [...]

b) Fallos judiciales de interpretación del “centro de los principales intereses”

81. Se han dictado varios fallos judiciales en los que se analiza el significado de la expresión “centro de los principales intereses”, tanto en la aplicación del Reglamento del Consejo Europeo como de leyes internas basadas en la Ley Modelo de la CNUDMI, y en los que se determinan los factores de posible importancia para impugnar la presunción enunciada en el artículo 16, párrafo 3, de la Ley Modelo en la medida en que se relaciona con sociedades deudoras y personas físicas. Ha surgido una serie de diferencias sutiles de enfoque, y cabría señalar que, a diferencia de lo que ocurre en otros Estados³⁴, en algunas jurisdicciones los tribunales podrían

³³ Esos arreglos contractuales seguirían siendo ejecutables al margen de la Ley Modelo sin necesidad de reconocimiento; nada de lo dispuesto en la Ley Modelo ni en la Guía para la incorporación y la interpretación tiene por objeto restringir la posibilidad de ejecutarlos.

³⁴ Por ejemplo, en el capítulo 15 del Código de Quiebras de los Estados Unidos (el capítulo en el que se incorpora la Ley Modelo de la CNUDMI) se había cambiado, en la versión inglesa la formulación de la presunción y en lugar de “proof to the contrary” se había utilizado “evidence to the contrary” (en el artículo 1516 c) se estipula que “En ausencia de pruebas en contrario, la sede social del deudor ... se presume que es el centro de los principales intereses del deudor”). Los antecedentes legislativos de ese cambio sugieren que se trataba de reflejar una cuestión de terminología, a saber, que en la forma en que se utiliza el término “evidence” en los Estados Unidos quizá refleje mejor el término “proof” que se utiliza en otros Estados anglófonos. Los fallos de los tribunales de los Estados Unidos deberán leerse en ese contexto.

requerir pruebas de mayor calidad o en mayor número para impugnar esa presunción.

82 a 85. [...]

86. La sentencia sobre el caso *Eurofood* atribuye considerable importancia a la necesidad de que sea previsible el lugar donde se ubica el centro de los principales intereses de un deudor. En el caso posterior de *Interedil* el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que la segunda oración del artículo 3 debe interpretarse en el sentido de que “el centro de los principales intereses de la empresa del deudor debía determinarse dando mayor importancia al lugar en que se encontraba la administración central de la empresa, que podía determinarse mediante factores objetivos verificables por terceros”. Cuando el lugar en que se encontraran los órganos de gestión y supervisión de la empresa coincidiera con el domicilio social y con el lugar en que se adoptaran las decisiones administrativas de la empresa, de forma que fuera verificable por las partes, la presunción no podía rebatirse. Sin embargo, cuando la administración central de una empresa no está en el mismo lugar que el domicilio social, se deberá proceder a una evaluación pormenorizada de todos los factores pertinentes a fin de determinar, de manera verificable por terceros, la localización del centro real de gestión y supervisión de la empresa y de la administración de sus intereses. En ese caso particular, el Tribunal dictaminó que la presencia de bienes de la empresa y la existencia de contratos de explotación financiera de esos bienes en un Estado Miembro distinto del de su domicilio social no podían considerarse factores suficientes para impugnar la presunción, a menos que la evaluación pormenorizada de todos los factores pertinentes apunte hacia ese otro Estado Miembro”³⁵.

87. [trasladado a la nota de pie de página del párrafo 81]

88. [suprimido]

89. En el caso *Bear Stearns*, el tribunal estadounidense consideró la cuestión de la determinación del centro de los principales intereses del deudor. La solicitud de reconocimiento hacía referencia a una empresa registrada en las Islas Caimán, que era objeto de un procedimiento de liquidación provisional en esa jurisdicción.

90. El tribunal puso de manifiesto el motivo del cambio que se había introducido en la presunción prevista en la legislación de los Estados Unidos, es decir, la sustitución de “proof” por “evidence”³⁶. Refiriéndose a los antecedentes legislativos de esa disposición, el juez dijo lo siguiente:

“La presunción de que el domicilio social es también el centro de los principales intereses del deudor se ha incluido por motivos de rapidez y conveniencia de la prueba cuando no hay ninguna oposición grave a ello”³⁷.

91 y 92. [...]

93. Agréguese la siguiente oración a la nota de pie de página: “La decisión fue confirmada en apelación ante el Tribunal de Distrito [2011 WL 4357421 (SDNY, 16 Sept. 2012)] y es ahora objeto de una nueva apelación”.

³⁵ *Interedil*, párr. 59.

³⁶ Véase la nota del párrafo 81.

³⁷ [Cita por completar.]

94. El fallo sobre el caso *Bear Stearns* fue recurrido sobre la base de que no se habían “reconocido” los principios de cortesía y cooperación y de que el juez supuestamente había interpretado de forma errónea la presunción. En la apelación, el juez no tuvo dificultad en dictaminar que el principio de cortesía había sido desplazado por el concepto de reconocimiento del procedimiento extranjero. El juez de apelación señaló que había que distinguir entre el “reconocimiento” y las “medidas”.

95. El tribunal de apelación confirmó la decisión del tribunal inferior en la que se afirmaba que correspondía al representante extranjero rebatir la presunción y que el tribunal tenía, por su parte, el deber de determinar que así se había hecho, aun cuando nadie se opusiera a esa presunción³⁸.

96. [...]

97. Oraciones 1 a 3 [...]; las oraciones 4 a 7, relativas al momento para determinar el centro de los principales intereses, han sido trasladadas al párrafo 102L.

98. Otros fallos son los dictados por tribunales ingleses en primera instancia y en apelación en el caso *Stanford International Bank*, en ese caso intervenía una solicitud de reconocimiento en Inglaterra de un procedimiento abierto en Antigua y Barbuda. En él se consideró si el criterio del “lugar desde donde se desempeñen las funciones administrativas principales” se había articulado en fallos anteriores de tribunales ingleses aplicable teniendo en cuenta al caso *Eurofood*.

99 a 101. [...]

102. Agréguese la siguiente oración al final del párrafo: “Casos ulteriores fallados con arreglo a la Ley Modelo han confirmado el requisito de verificabilidad³⁹”.

c) Revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación

102A. Las revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación de la Ley Modelo [que la Comisión aprobó en 2013] responden a la incertidumbre e imprevisibilidad que han surgido con respecto a la interpretación del concepto de centro de los principales intereses. Las notas de la Guía revisada (párrs. 123 a 123E) en el sentido de que cuando el centro de los principales intereses del deudor coincide con su lugar de inscripción, no se planteará ningún problema respecto de la impugnación de la presunción prevista en el artículo 16, párrafo 3, de la Ley Modelo. Sin embargo, el centro de los principales intereses del deudor puede de hecho no coincidir con el lugar de su inscripción y la parte que alegue que el centro de los principales intereses no se encuentra en ese lugar deberá probar al tribunal su ubicación. El tribunal ante el que se recurra deberá considerar por sí mismo la ubicación del centro de los principales intereses del deudor y determinar si se cumplen los requisitos de la Ley Modelo. En algunos casos, le podrá ayudar en esa tarea la información incluida en el mandamiento del tribunal de origen en cuanto a la índole del procedimiento extranjero⁴⁰, aunque ese mandamiento evidentemente

³⁸ *Bear Stearns* (en apelación), pág. 335.

³⁹ *Lightsquared, Massachusetts Elephant & Castle; Millennium Global; Ackers v Saad* ([2010] FCA 221); *Gerova*.

⁴⁰ A modo de ejemplo, el tribunal canadiense del caso *Cinram International* esbozó los factores que los demandantes habían aducido y que indicaban que la ubicación del centro de los principales intereses del deudor se encontraba en el Canadá. El tribunal indicó que había

no es vinculante para el tribunal ante el que se recurre. En los casos en que el domicilio social del deudor no coincide con el centro de sus principales intereses, este se determinará mediante factores que indiquen a los que hacen negocios con el deudor (especialmente los acreedores) dónde se encuentra.

102B. En las revisiones de la Guía se afirma que los factores principales que se exponen a continuación, considerados en conjunto, tenderán a indicar si el lugar en el que se ha abierto el procedimiento extranjero es el centro de los principales intereses del deudor. Esos factores son el lugar a) en que se lleve a cabo la administración central del deudor, y b) que sea fácilmente verificable para los acreedores.

102C. Cuando esos factores principales no se presten para determinar fácilmente el centro de los principales intereses del deudor, podrán considerarse otros relacionados con sus negocios. Tal vez el tribunal tenga que asignar una mayor o menor importancia a un determinado factor, según las circunstancias del caso de que se trate. No obstante, en todos los casos el proceso ha de considerarse de manera integral y estar destinado a determinar que el lugar del procedimiento extranjero se corresponde efectivamente con el centro de los principales intereses del deudor, que sea fácilmente verificable para los acreedores.

102D. Entre esos otros factores cabe citar los siguientes: el lugar en que se encuentran los libros de contabilidad y los registros del deudor; el lugar en el que se organiza o autoriza la financiación o se administra el sistema de gestión del efectivo, el lugar en que se hallan los activos u operaciones principales del deudor; el lugar en que se encuentra el banco principal del deudor; el lugar en el que están sus empleados; el lugar en que se determina la política comercial; la jurisdicción de la legislación de control o de la legislación por la que se rigen los principales contratos de la empresa; el lugar desde el que se gestiona la política de compras y ventas y se administra el personal, las cuentas por pagar y los sistemas informáticos; el lugar en el que se organizan los contratos (de suministro); el lugar desde el que se dirige la reorganización de la empresa del deudor; la jurisdicción cuya legislación se aplica a la mayoría de los litigios; el lugar en el que el deudor es objeto de supervisión o reglamentación, y el lugar por cuya legislación se rige la preparación y auditoría de las cuentas y en el que estas se preparan y auditan.

102E. La Guía indica que el orden en el que se enumeran esos otros factores no pretende indicar la prioridad o importancia que ha de darse a cada uno de ellos ni tampoco se pretende que sea una lista exhaustiva de los factores pertinentes; el tribunal podría considerar aplicables otros factores en un caso determinado.

102F. En varios de los casos fallados que se examinaron en el curso de la revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación se analizaban los factores determinantes del centro de los principales intereses, y se adoptó el criterio de concentrarse en unos cuantos factores principales. En el caso *Massachusetts Elephant & Castle*, el tribunal canadiense tuvo en cuenta tres

incluido ese esbozo relativo al centro de los principales intereses “a efectos de información únicamente. Este tribunal reconoce claramente que es función del tribunal ante el que se recurre -en este caso, el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos del Distrito de Delaware- determinar la ubicación del centro de los principales intereses y decidir si ese procedimiento, entablado con arreglo a la Ley de acuerdos con acreedores de empresas canadienses es un “procedimiento principal extranjero” a los efectos del capítulo 15” (párr. 42).

factores principales, a saber, que el lugar era aquel a) donde se encontraban los bienes u operaciones principales del deudor; b) donde se administraban los negocios del deudor; y c) cuya ubicación resultaba fácilmente verificable por un número apreciable de acreedores como el centro de operaciones del deudor, al tiempo que hizo notar que si bien otros factores podrían también considerarse aplicables, tal vez se debieran considerar de importancia secundaria y tener en cuenta solo en la medida en que corroboraban los tres factores mencionados⁴¹. Esos factores se tuvieron en cuenta en el caso *Lightsquared*⁴², en el que el juez canadiense también observó que si bien en la mayoría de los casos esos factores principales apuntaban a una única jurisdicción como centro de los principales intereses del deudor, puede haber algunos casos en que esos factores entren en conflicto y se requiera un examen más minucioso de los hechos. Tal vez el tribunal tenga que asignar una mayor o menor importancia a un determinado factor, según las circunstancias del caso de que se trate. No obstante, en todos los casos, afirmó el juez, el examen tiene por objeto determinar que el lugar del procedimiento corresponde efectivamente al de la verdadera sede o al principal centro de negocios del deudor, conforme a lo que cabía esperar a juicio de quienes tuvieron trato con la empresa antes de la apertura del procedimiento.

102G. En el caso *Think3*⁴³, el tribunal japonés debía dictaminar si el procedimiento extranjero principal era el procedimiento entablado en los Estados Unidos o el entablado en Italia. Tanto en primera instancia como en el recurso de apelación, los tribunales consideraron los factores que se examinaban en el curso de la revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación y sopesaron también si el lugar que servía de sede o centro neurálgico de los negocios del deudor era un elemento de los factores que era preciso tomar en consideración.

d) Traslado del centro de los principales intereses

102H. El centro de los principales intereses del deudor puede trasladarse antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, en algunos casos en fecha muy próxima a esa apertura e incluso entre el momento de la solicitud de apertura y la apertura efectiva del procedimiento⁴⁴. Siempre que haya pruebas de que se ha realizado un traslado en fecha muy próxima a la apertura del procedimiento extranjero, puede ser conveniente que el tribunal ante el que se recurra, al

⁴¹ *Massachusetts Elephant & Castle*, párr. 30.

⁴² *Lightsquared*, párrs. 25 y 26.

⁴³ En la ley japonesa de incorporación de la Ley Modelo en el derecho interno se utiliza la expresión “lugar principal de los negocios” en lugar de “centro de los principales intereses”, y no se establece ninguna presunción con respecto al domicilio social que sea equivalente a la del artículo 16, párrafo 3, de la Ley Modelo. Sin embargo, como explica el tribunal de primera instancia del caso *Think3*, se considera que la expresión “lugar principal de los negocios” tiene en la legislación japonesa básicamente el mismo significado que “centro de los principales intereses”, y era preciso tener en cuenta y examinar los precedentes judiciales de otros países respecto del centro de los principales intereses, así como la orientación de las deliberaciones pertinentes de la CNUDMI [capítulo 3, cuestión 2-2(2), pág. 19].

⁴⁴ En algunos de los ejemplos citados el propósito del traslado era dar acceso al deudor a un procedimiento de insolvencia, por ejemplo, de reorganización, que atendiera en mayor medida sus necesidades que el que le ofrecía la legislación vigente en su anterior centro de intereses principales. En otros casos, el traslado del centro de los principales intereses podía haber obedecido al propósito de frustrar las expectativas legítimas de acreedores y terceros.

determinar si reconoce o no el procedimiento, sopesa más detenidamente los factores indicados en los párrafos 102B y 102D y tenga en cuenta las circunstancias del deudor desde un punto de vista más general. En particular, la condición de que terceros puedan verificar fácilmente cuál es el centro de los principales intereses será más difícil de cumplir si el traslado ha tenido lugar en fecha muy próxima a la apertura del procedimiento.

102I. En el caso *Interdil*, el Tribunal Europeo de Justicia examinó el efecto que tendría el traslado del domicilio social del deudor antes de que comenzara el procedimiento de insolvencia. Dictaminó que cuando el domicilio social de una empresa deudora se traslada antes de que se inscribiera una solicitud de iniciación de un procedimiento de insolvencia, se presumía que el centro de las principales actividades de la empresa era el lugar del nuevo domicilio social⁴⁵.

102J. No es probable que un deudor pueda trasladar su domicilio social (o su residencia habitual) tras la apertura del procedimiento de insolvencia, ya que en muchos casos el régimen de la insolvencia contiene disposiciones concretas para impedirlo. En cualquier caso, si eso ocurriera, no afectaría a la decisión sobre el centro de los principales intereses a los efectos de la Ley Modelo, ya que el momento que se ha de tener en cuenta para determinarlo es el de la apertura del procedimiento extranjero, como se analiza más adelante en el párrafo 102O.

e) Momento de la determinación del centro de los principales intereses

102K. La Ley Modelo no indica explícitamente la fecha que servirá de punto de referencia para determinar el centro de los principales intereses (o establecimiento), salvo por la disposición establecida en el artículo 17 2 a), de que el procedimiento extranjero se reconocerá como procedimiento principal “si se está tramitando en el Estado donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses”. El uso del tiempo presente en el artículo 17 exige que el procedimiento extranjero esté en curso o pendiente en el momento de adoptarse la decisión sobre el reconocimiento; si en ese momento el procedimiento respecto del cual se solicita el reconocimiento ya no está en curso ni está pendiente en el Estado en que se procedió a su apertura, no existe ningún procedimiento reconocible en virtud de la Ley Modelo.

102L. A nivel judicial, la cuestión del momento ha sido ya objeto de examen. En el caso *Betcorp*, por ejemplo, el juez dictaminó que el momento a considerar para determinar el centro de los principales intereses era el momento de la presentación de la solicitud de reconocimiento⁴⁶. Esa interpretación parece derivar del tiempo presente que se utiliza para redactar la definición de “procedimiento extranjero principal” por el que se entiende “el procedimiento extranjero que se siga en el Estado donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses”. Un problema semejante se plantea en relación con el lugar de un “establecimiento”, atendiendo a la definición de “procedimiento extranjero no principal”, un “procedimiento extranjero ... que se siga en un Estado en que el deudor tenga un establecimiento”. El enfoque del caso *Betcorp* se siguió en los casos *In Re Ran (Fifth Circuit)* y *British American Insurance*.

⁴⁵ *Interdil*, párr. 59.

⁴⁶ *Betcorp*, pág. 292.

102M. En casos más recientes los tribunales han dictaminado que el momento pertinente para determinar el centro de los principales intereses es el momento de iniciación del procedimiento extranjero. En el caso *Millennium Global*, el juez estadounidense de primera instancia observó que el procedimiento de reconocimiento estaba supeditado al procedimiento extranjero y que la fecha de solicitud de reconocimiento es una simple casualidad y puede ocurrir en cualquier momento, incluso algunos años después de la iniciación del procedimiento extranjero. Además, si se considera el centro de los principales intereses como el equivalente del lugar principal de los negocios del deudor, interpretación aplicada por una serie de tribunales, el centro de los principales intereses debe referirse a los negocios del deudor antes de la iniciación del procedimiento extranjero, puesto que después de la iniciación, en particular del procedimiento de liquidación, lo común es que cesen los negocios y no haya un lugar de negocios⁴⁷. Esta decisión se siguió en el caso *Gerova*, en el que el juez estadounidense observó que en la fecha de solicitud de reconocimiento, el deudor no tenía actividades o vinculaciones comerciales en las Bermudas, exceptuadas las actividades del liquidador encargado del cierre de los negocios del deudor⁴⁸. En el caso *Think3*, el tribunal japonés siguió el criterio del momento del registro de la solicitud de iniciación del procedimiento extranjero o la iniciación de ese procedimiento⁴⁹, decisión que fue confirmada en apelación. El tribunal japonés de primera instancia observó que si el momento de la determinación se regía por la fecha de la solicitud de reconocimiento, en los casos en que había múltiples aplicaciones de reconocimiento del mismo procedimiento extranjero en diferentes países, el momento de la determinación terminaría siendo diferente en cada uno de esos países con la consiguiente falta de unificación y con resultados diferentes en diferentes tribunales. Además, afirmó el tribunal, el empleo de la fecha de la aplicación de reconocimiento podría inducir a una elección arbitraria del momento de aplicar dicho reconocimiento.

102N. En el caso *Interedil*, cuyo fallo se dictó con arreglo al Reglamento del Consejo Europeo, el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que el elemento esencial para determinar el tribunal competente es la ubicación del centro de los principales intereses del deudor en el momento en que se haya inscrito la solicitud de apertura de procedimientos de insolvencia.

102O. En las revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación se indica que, habida cuenta de las pruebas que han de presentarse junto con la solicitud de aplicación de reconocimiento, de conformidad con el artículo 15 y de la importancia asignada a la resolución por la que se declara abierto el procedimiento extranjero y se nombra al representante extranjero, la fecha de apertura de ese procedimiento es la fecha adecuada para determinar la localización del centro de los principales intereses del deudor. La elección de esa fecha ofrece un criterio que puede aplicarse con certeza en todos los procedimientos de insolvencia. Asimismo, resuelve problemas que puedan surgir cuando la actividad comercial del deudor haya cesado en el momento de la solicitud de reconocimiento⁵⁰ cuando,

⁴⁷ *Millennium Global*, págs. 12 a 19; el tribunal de apelaciones no se ocupó de la cuestión del momento en que se debía determinar el centro de los principales intereses y el establecimiento.

⁴⁸ *Gerova*, pág. 10.

⁴⁹ Tribunal Superior, capítulo 3-2, pág. 6; Tribunal de Distrito, capítulo 3, asunto 2-1, págs. 12 a 14.

⁵⁰ En el caso *Fairfield Sentry*, el tribunal estadounidense señaló que el deudor había en efecto

como puede ocurrir en casos de reorganización, no es la entidad del deudor la que continúa teniendo un centro de intereses principales, sino, más bien, la entidad reorganizadora, así como las circunstancias en que se produce un cambio de domicilio entre el comienzo del procedimiento extranjero y la solicitud de reconocimiento con arreglo a la Ley Modelo.

103 a 107. [suprimidos]

f) Abuso del proceso

108. Cuando se plantee una solicitud de reconocimiento, ¿deberá estar facultado el tribunal para tener en cuenta la posibilidad de que se esté cometiendo un abuso del proceso como justificación para denegar el reconocimiento? Ninguna disposición de la Ley Modelo de la CNUDMI sugiere de por sí que deban tenerse en cuenta, cuando se solicite un reconocimiento, circunstancias externas. La Ley Modelo prevé que la respuesta a la solicitud se determine en función de los criterios concretos que se derivan de las definiciones de “procedimiento extranjero”, “procedimiento extranjero principal” y “procedimiento extranjero no principal”. Dado que lo que constituye abuso del proceso depende de la legislación o las normas procesales internas, la Ley Modelo no impide expresamente que los tribunales ante los que se recurra apliquen la legislación interna, en particular las normas procesales, para hacer frente a un abuso del proceso que hayan podido advertir.

109. [suprimido]

110. [trasladado al artículo 6 - párr. 51A]

4. Procedimiento no principal: el “establecimiento”

a) Introducción

111 a 113. [...]

b) Decisiones de los tribunales sobre la interpretación del “establecimiento”

114. [...]

115. Es posible que deba prestarse más atención a los términos “con medios humanos y bienes o servicios” que se utilizan en la definición de “establecimiento”. En el tipo de actividad empresarial local parece implícito que bastará que haya una actividad económica realizada por seres humanos y que entrañe bienes o servicios para satisfacer los requisitos de la definición del término “establecimiento”. En el caso *Interdil*, fallado con arreglo al Reglamento del Consejo Europeo, el Tribunal

clausurado sus negocios algún tiempo antes de la iniciación del procedimiento de liquidación y antes de que se presentara la solicitud de reconocimiento y que durante un período prolongado las actividades que había realizado se relacionaban únicamente con la liquidación de sus negocios. El juez estimó que era procedente tener en cuenta ese período prolongado al determinar el centro de los principales intereses del deudor (pág. 64). En el caso *British American Insurance*, el tribunal dictaminó que el centro de los principales intereses del deudor puede coincidir con el lugar de residencia del representante extranjero cuando este se instala en el lugar durante un período prolongado, y traslada a él la totalidad de las principales actividades comerciales del deudor (o interrumpe las actividades de la empresa), a raíz de lo cual los acreedores y otras partes podrían considerar que los negocios del deudor están situados en el mismo lugar donde se encuentra el [representante extranjero] (pág. 914).

Europeo de Justicia observó que el hecho de que la definición vincule la realización de una actividad económica a la presencia de recursos humanos muestra que se requiere un grado mínimo de organización y de estabilidad. A la inversa, de ahí se desprende que la sola presencia de bienes aislados o de cuentas bancarias no cumple, en principio, los requisitos de la clasificación como “establecimiento”.

116. Agréguese la siguiente oración al final del párrafo: “En el caso *Williams c. Simpson* (No. 5) la dificultad radicaba en que mientras que, en virtud del derecho inglés, el cierre de un negocio en el Reino Unido (mediante la cancelación de las deudas) constituía un motivo por el que el deudor podría quedar sometido a las leyes de insolvencia de Inglaterra, ello no equivalía a un “establecimiento” tratándose de una persona que ha estado retirada por cerca de 12 años y no tiene negocios existentes (reales) en ese país”.

c) Momento de la determinación de la existencia de un establecimiento

116A. Como ya se señaló, la Ley Modelo no indica explícitamente el momento pertinente para determinar el centro de los principales intereses del deudor. Lo mismo cabe afirmar con respecto a la determinación de la existencia de un establecimiento. En las revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación se sugiere que la fecha de iniciación del procedimiento extranjero es la fecha apropiada para determinar la existencia de un establecimiento en el caso del deudor.

D. Medidas previstas

1. Introducción

117 a 120. [...]

121. Para determinar si se ha eliminado o modificado en el Estado promulgante alguna medida otorgable de cualquier tipo (automática o discrecional) prevista en la Ley Modelo, es preciso considerar la ley concreta por la que se incorpora la Ley Modelo⁵¹. Una vez se haya determinado qué medidas pueden otorgarse, corresponde al tribunal competente definir las medidas necesarias y convenientes en cada caso, que se sumarán a las medidas automáticas que se derivan del reconocimiento de un procedimiento como “principal”. El fallo del caso *Bear Stearns* de que la cuestión de las medidas otorgables se debería distinguir claramente de la cuestión del reconocimiento fue corroborado en el caso *Atlas Shipping*, en el que el tribunal estadounidense dictaminó que, una vez que un tribunal reconoce un procedimiento extranjero principal, el capítulo 15 del Código de Quiebras de los Estados Unidos prevé expresamente que el tribunal ejerza su facultad discrecional para adecuar, según proceda, las medidas posteriores al reconocimiento de forma compatible con

⁵¹ Los Estados que han promulgado legislación basada en la Ley Modelo han adoptado diferentes enfoques. Por ejemplo, el alcance de la paralización automática es más amplio en los Estados Unidos (para adaptarlo al capítulo 11 de su Código de Quiebras). En México la paralización no impide la continuación de todas las acciones individuales, aunque no las medidas de ejecución. El Japón y la República de Corea prevén que las medidas que se adopten después del reconocimiento dependen de la decisión discrecional que adopte el tribunal en cada caso, en lugar de aplicarse automáticamente según lo previsto en la Ley Modelo.

el respeto de los principios de cortesía internacional⁵². El fallo fue corroborado también en el caso *Metcalfe & Mansfield*, en el que se había pedido a un tribunal estadounidense que ejecutara determinados mandamientos dictados por un tribunal canadiense para que se adoptaran ciertas medidas, que eran más amplias que las que habría permitido la legislación de los Estados Unidos. El tribunal indicó que el principio de la cortesía internacional no obligaba a que las medidas otorgadas en el procedimiento extranjero y las otorgadas en los Estados Unidos fuera idénticas. La cuestión fundamental era determinar si el procedimiento extranjero cumplía las normas fundamentales de equidad en los Estados Unidos; el tribunal falló que el procedimiento canadiense cumplía ese requisito⁵³.

2. Medidas provisionales⁵⁴

122 a 124. [...]

125. Agréguese las oraciones siguientes a la nota de pie de página: “En el mismo caso, se presentó una segunda solicitud de medidas provisionales que permitieran el examen de algunas personas con miras a determinar cuestiones de propiedad de los bienes que habían sido embargados con arreglo a la orden de registro. El tribunal denegó la solicitud con el argumento de que la medida solicitada no era de carácter urgente, como lo exigía el artículo 19, párrafo 1, de la Ley Modelo. Dictaminó que puesto que los bienes cuya propiedad estaba en duda habían sido ya embargados y la cuestión de la propiedad vendría al caso después de que se determinara el reconocimiento del procedimiento extranjero, la orden solicitada era innecesaria”.

126 a 129. [...]

129A. En varios casos se han examinado cuestiones relacionadas con la protección adecuada de los acreedores. En el caso *Sivec*, el deudor obtuvo el reconocimiento de un procedimiento de reorganización ordenado en Italia como procedimiento extranjero principal y la modificación de la paralización automática para permitir la litigación en los Estados Unidos de dos demandas de posible compensación recíproca. A raíz de la litigación, uno de los acreedores estadounidenses solicitó medidas de amparo de la paralización, a fin de hacer posible la compensación recíproca entre las dos sumas objeto de las sentencias. El deudor italiano pidió que se ejecutara el proceso entablado en Italia, lo que, al parecer, significaría que el acreedor estadounidense no podría invocar la compensación recíproca entre las dos sumas objeto de las sentencias. El tribunal estadounidense dictaminó que no reconocería el principio de cortesía internacional respecto del procedimiento italiano, puesto que el deudor italiano “no había suministrado información relativa a la ley italiana aplicable o a la situación del caso de quiebra en Italia ni había cumplido el requisito de la carga de la prueba al solicitar que se reconociera el principio de cortesía”. El tribunal expresó su particular preocupación por la falta de notificación al acreedor estadounidense, concluyó que se echaban de menos los elementos básicos del debido proceso y que los intereses del acreedor estadounidense no quedaban debidamente protegidos⁵⁵.

⁵² *Atlas Shipping*, pág. 78.

⁵³ *Metcalfe y Mansfield*, págs. 697 y 698.

⁵⁴ El resumen que sigue se basa sustancialmente en la Guía para la incorporación y la interpretación, párrs. 135 a 140.

⁵⁵ *Sivec*, págs. 324 a 326.

129B. En el caso *SNP Boat Service*, el concepto de “protección suficiente” se interpretó de manera más restringida. En ese caso, un acreedor canadiense impugnó la solicitud del deudor de un procedimiento de insolvencia francés de que se repatriaran a Francia bienes que se encontraban en los Estados Unidos basándose en el argumento de que sus intereses no estarían “suficientemente protegidos” en el procedimiento entablado en Francia. En la apelación, el tribunal estadounidense estableció una distinción entre las medidas previstas en virtud del artículo 21.2 y el artículo 22.1, de la Ley Modelo, dado que este último establecía de manera más general que el tribunal puede otorgar una medida con arreglo a los artículos 19 o 21 únicamente si “quedan debidamente protegidos los intereses de los acreedores y de otras personas interesadas incluido el deudor”⁵⁶. Aunque el acreedor que había recurrido era canadiense, el tribunal dictaminó que no estaba impedido de asegurarse de que los intereses de los acreedores extranjeros en general estaban suficientemente protegidos antes de decidir el envío de bienes a la jurisdicción extranjera, aunque rechazó la idea de que pudiera hacer averiguaciones sobre el tratamiento individual que el acreedor en cuestión recibiría en Francia⁵⁷.

3. Medidas automáticas tras el reconocimiento de un procedimiento principal⁵⁸

130 a 133. [...]

134. [...] Agréguese la siguiente nota de pie de página: “En el caso *JSC BTA Bank* [434 BR 334 (Bankr. S.D.N.Y. 2010)], el tribunal estadounidense dictaminó que el alcance de la paralización automática [aplicable en virtud del Código de Quiebras] se limitaba a procedimientos que podían tener efecto en los bienes de un deudor localizado en los Estados Unidos. Un arbitraje llevado a cabo en Suiza tras la iniciación del procedimiento entablado con arreglo al Capítulo 15 no violaba la paralización automática puesto que la ley aplicable en el centro de los principales intereses del deudor no paralizaba el arbitraje y el deudor había participado en él, al parecer, sin poner objeción. Igualmente, la paralización automática no se aplicaba a acciones respecto de incumplimientos del contrato simplemente después del reconocimiento por parte de un deudor extranjero o de no deudores relacionados con el caso”.

135. [...]

136. [...] Agréguese la siguiente nota de pie de página: “El derecho de los Estados Unidos, por ejemplo, prevé una excepción para las dependencias gubernamentales

⁵⁶ *SNP Boat Service*, pág. 11.

⁵⁷ En otro caso de los Estados Unidos, *In re Lee* [472 B.R. 156 (Bankr. D. Mass. 2012)], el representante extranjero de deudores domiciliados en Hong Kong solicitó que se le reconociera la posesión y control de bienes de propiedad de los deudores en los Estados Unidos, declarando en su testimonio que, en virtud del derecho de Hong Kong, tenía la obligación de tomar posesión de los intereses representados en esos bienes y que, como profesional razonable, tenía la obligación de proteger y maximizar el valor de los bienes de sus representados y respetar las restricciones aplicables a la transferencia. El tribunal estadounidense dictaminó que el representante extranjero había cumplido el requisito de la carga de probar que acreedores y deudores estarían suficientemente protegidos si se otorgaba el mandamiento de posesión, y que los deudores no habían cumplido el requisito de “probar de forma definitiva la ausencia de protección suficiente”.

⁵⁸ El resumen que figura a continuación se basa sustancialmente en la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación, párrs. 141 a 153.

que actúan en su capacidad reglamentaria o de policía. En el caso *Nortel Networks Corp.*, [669 F.3d 128 (3d Cir. 2011)], el organismo regulador de las pensiones del Reino Unido solicitó la iniciación de un procedimiento en relación con un déficit de financiación en el Fondo de pensiones Nortel del Reino Unido y, con arreglo a la ley del Reino Unido, notificó a las empresas subsidiarias de Nortel en los Estados Unidos y el Canadá, que se encontraban todas enfrentadas a casos paralelos de quiebra total. Los tribunales estadounidenses dictaminaron que puesto que el organismo regulador de las pensiones del Reino Unido actuaba como fideicomisario en nombre de acreedores privados que perseguían un fin pecuniario y no como ente regulador que actúa para proteger la seguridad o bienestar públicos, la acción que proponía violaría la paralización automática”.

137. [...]

4. Medidas otorgables a partir del reconocimiento⁵⁹

a) Las disposiciones de la Ley Modelo

138 a 143. [...]

144. Agréguese al final de la primera oración una remisión a los párrafos 129 a 129C.

145. [...]

146. En una segunda apelación, el Tribunal Supremo revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones y dictaminó que los daños estaban sujetos a las normas ordinarias del derecho internacional privado que impedían la ejecución porque los demandantes no estaban sometidos a la jurisdicción del tribunal extranjero⁶⁰. El tribunal dictaminó asimismo que no había ninguna disposición en la Ley Modelo que indicara que se aplicaría al reconocimiento y ejecución de fallos extranjeros contra terceros.

b) Enfoques de los problemas que suscitan las medidas discrecionales

147 a 149. [...]

149A. Otro ejemplo lo ofrece el caso *In re Vitro*, en el que el tribunal de apelaciones de los Estados Unidos trazó un enfoque para analizar solicitudes de otorgamiento de medidas con arreglo a los artículos 7 y 21 que estipulan que un tribunal determine en primer lugar si la medida solicitada por un representante extranjero está comprendida en las categorías enumeradas en el artículo 21. De no ser así, el tribunal debería dictaminar si la medida solicitada podría considerarse una “medida apropiada” con arreglo al artículo 21, párrafo 1, lo cual entraña el examen para determinar si la medida solicitada ha sido otorgada anteriormente con arreglo a la ley aplicable antes de la promulgación del capítulo 15 y si sería otorgable en virtud de alguna otra disposición conforme a la ley estadounidense. En tercer lugar, si las

⁵⁹ El presente resumen está básicamente tomado de la Guía para la incorporación al derecho interno y la interpretación, párrs. 154 a 160.

⁶⁰ A la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido en el caso *Rubin* se sumó una apelación en el caso *New Cap Reinsurance Corp Ltd & Anor V Grant and others* [2012] UKSC 46. En este caso, el Tribunal Supremo dictaminó que el fallo extranjero podía ejecutarse porque New Cap se había sometido a la jurisdicción presentando pruebas de la deuda en el procedimiento de insolvencia extranjero.

medidas solicitadas exceden el ámbito de la medida otorgable con arreglo a la ley anterior u otorgable actualmente en virtud de la ley estadounidense, el artículo 7 funcionaría como una disposición englobadora que incluye modalidades de medidas “más extraordinarias” que las permitidas en virtud de las disposiciones ya sea específicas o generales del artículo 21⁶¹. El tribunal razonó que ese marco impediría a los tribunales someter las medidas previstas en virtud de artículo 7 a las mismas limitaciones que las medidas previstas en virtud del artículo 21, a menos que esas limitaciones fuesen específicamente aplicables, y evitarían “modalidades de aplicación que abarquen todas” las posibilidades previstas en el artículo 7 y “amplíen prematuramente el alcance del capítulo 15 más allá de lo previsto en el derecho internacional de la insolvencia vigente”⁶².

149B. Aplicando ese marco a los hechos sometidos a su consideración, el tribunal confirmó la denegación de la solicitud del representante extranjero de ejecutar una orden de confirmación de un plan de reorganización mexicano que sustituía y de hecho dejaba sin efecto las obligaciones de las filiales del deudor mexicano que poseían pagarés garantizados emitidos por el deudor pero que no habían utilizado para iniciar procedimientos de insolvencia. El tribunal dictaminó, en primer lugar, que el artículo 21, párrafos 1 y 2, no preveía la exoneración de las obligaciones de fiadores no deudores. Luego, el tribunal dictaminó que el otorgamiento general de las medidas previstas en el párrafo 1 del artículo 21 no cobijaba la medida solicitada dado que las exoneraciones de terceros no deudores mediante un procedimiento de quiebra que no hubiesen sido acordadas “no eran en general otorgables” de conformidad con el derecho de los Estados Unidos y estaban “expresamente prohibidas” en ese tribunal en concreto⁶³. Pasando al artículo 7, el tribunal observó que ese tipo de exoneraciones eran a veces otorgables en otros tribunales y que, por consiguiente, la medida solicitada no quedaba excluida en virtud del artículo 7. Sin embargo, el tribunal concluyó que puesto que *Vitro* no había presentado pruebas de que existían circunstancias extraordinarias que bastaran para demostrar un caso a favor de las exoneraciones de terceros no deudores en virtud de la jurisprudencia de los tribunales que las habían autorizado, el tribunal inferior no se había excedido de su facultad discrecional al denegar la medida solicitada en virtud del artículo 7⁶⁴.

c) Medidas otorgables en los casos en que haya antecedentes de operaciones sospechosas

150 a 153. [...]

⁶¹ *Vitro*, párr. 19.

⁶² *Vitro*, párr. 20.

⁶³ *Vitro*, párr. 22.

⁶⁴ La denegación del reconocimiento de exoneraciones de terceros en el caso *Vitro* contrasta con su reconocimiento en el caso *Metcalfe & Mansfield*. En este último caso el tribunal dictaminó que el tribunal canadiense aprobó medidas a favor de terceros no deudores en circunstancias limitadas acordes con la restringida aplicación del artículo 7 en los tribunales estadounidenses. Por ello, el tribunal estadounidense dictaminó que las órdenes otorgadas en el procedimiento extranjero debían ejecutarse.

E. Cooperación y coordinación

1. Introducción

154 a 156. [...]

157. Esos artículos dejan que sea el tribunal competente, y el administrador de la insolvencia bajo su supervisión, los que decidan cuándo y de qué forma cooperarán. La Ley Modelo no supedita la cooperación de un tribunal local (o de la persona o del órgano mencionados en los artículos 25 y 26) con un tribunal o un representante extranjero a que exista un fallo formal sobre el reconocimiento del procedimiento extranjero. En consecuencia, la cooperación puede tener lugar en una etapa temprana y antes de que se formule la solicitud de reconocimiento. Dado que los artículos del capítulo 4 se aplican a las cuestiones que se mencionan en el artículo 1, se puede otorgar la cooperación con respecto no solo a las solicitudes de asistencia presentadas en el Estado promulgante, sino también a las solicitudes en relación con un procedimiento que se esté tramitando en el Estado promulgante con fines de prestación de asistencia en el extranjero (véase también el artículo 5). Además la cooperación no se limita a los procedimientos extranjeros en el sentido del artículo 2 a), que los habilitaría para el reconocimiento de conformidad con el artículo 17 (es decir, independientemente de que sean principales o no principales), por lo cual podrá otorgarse la cooperación con respecto a procedimientos iniciados sobre la base de la presencia de bienes.

158. [...]

2. Cooperación

159. [...]

160. [...]

a) [...]

b) Agréguese a la nota de pie de página que viene después de la palabra “interesadas” las oraciones siguientes: “En el caso *Chow Cho Poon*, el tribunal señaló que debería darse el reconocimiento explícito de cooperación por parte de los tribunales de que se trataba, ya que no es posible que un tribunal coopere con otro sin que este tenga conocimiento de ello. El tribunal observó que el artículo 27 de la Ley Modelo contempla que la cooperación se inicie ya sea mediante una solicitud cursada por un tribunal a otro o mediante la aceptación de un plan convenido (párr. 56)”.

c) a e) [...]

161 a 165. [...]

165A. Un ejemplo diferente son los esfuerzos de los tribunales por cooperar restringiendo los efectos de sus propias decisiones cuando estas discrepan de decisiones de tribunales de otros Estados. En el caso *Perpetual Trustee Company Ltd v Lehman Bros. Special Financing Inc*⁶⁵, una serie de demandas de ese tipo

⁶⁵ [2009] EWHC 2953 párrs. 12 a 23. En *Belmont Park Investments Pty Ltd v BNY Corporate Trustee Services Ltd.*, ([2011] UKSC 38), el Tribunal Supremo inglés hizo el siguiente resumen de las comunicaciones cursadas entre los tribunales ingleses y estadounidenses (párr. 33):

movió a un tribunal inglés a responder al tribunal de los Estados Unidos para explicar las etapas seguidas y las decisiones adoptadas en Inglaterra e invitar al juez estadounidense a no dictar, en aquel momento, ninguna orden formal que pudiera discrepar de las órdenes que se dictaran en Inglaterra⁶⁶. Sabiendo que su decisión discreparía directamente de la del tribunal inglés, el tribunal estadounidense expuso su opinión de la jurisprudencia, si bien no exigió el cumplimiento inmediato por las partes. Los tribunales examinaron los puntos en conflicto pero no llegaron a ninguna solución, aunque algunos de ellos se resolvieron posteriormente en el caso estadounidense.

166. Otro ejemplo de cooperación es el intercambio de correspondencia entre uno de los tribunales que intervienen en el procedimiento y que solicita asistencia y otro tribunal, que responde favorablemente a esa petición. En el caso *In re Lehman Brothers Australia Limited*⁶⁷, el tribunal examinó el efecto de las decisiones adoptadas en los casos Lehman en los Estados Unidos y en el Reino Unido sobre las responsabilidades estatutarias del liquidador de las entidades australianas y la solicitud de dichos liquidadores de que el tribunal se comunicara con el tribunal de los Estados Unidos. El tribunal australiano se abstuvo de hacerlo en ese momento arguyendo que su intervención podría repercutir en las decisiones del tribunal estadounidense sobre determinadas cuestiones; afectar el principio de la cortesía internacional, que se basaba en la deferencia común y el respeto mutuo, y ser considerada por el juez de los Estados Unidos como una injerencia injustificada; además, la solicitud se había formulado a instancia de parte y no se había escuchado a todas las partes interesadas y la cooperación entre el tribunal australiano y cualquier tribunal extranjero debería, en general, darse en virtud de un marco o un protocolo previamente aprobados por el tribunal y que fuera conocido por las partes en el procedimiento pertinente. No obstante, el juez estuvo de acuerdo en que podría ser conveniente comunicarse por escrito con el juez de los Estados Unidos para informarle de la solicitud en curso y para preguntarle si cabría establecer un protocolo para futuras comunicaciones. Se adjuntó a la sentencia un proyecto de carta que se enviaría al tribunal estadounidense.

167 a 170. [...]

3. Coordinación

171 a 187. [...]

“Tras el intercambio de comunicaciones entre el Tribunal Superior de Inglaterra y el Tribunal de Quiebras de Nueva York, se convino en que, a fin de limitar posibles conflictos entre las decisiones adoptadas en las dos jurisdicciones, la medida se limitaría a una declaración: *Perpetual Trustee Co. Ltd v BNY Corporate Trustee Services Ltd*. [2010 2 BCLC 237]; *In re Lehman Bros Holdings Inc* (2010) 422 BR 407 (Bankr. SDNY)”.

⁶⁶ *Perpetual Trustee*, párrs. 41 a 50.

⁶⁷ *Parbery; in the matter of Lehman Brothers Australia Limited* (in liq) [2011] FCA 1449 [CLOUT, caso núm. 1215].

Anexo I

Resúmenes de casos

1. *In re ABC Learning Centres Limited* 445 B.R. 318 (Bankr. D. Del 2010)
[CLOUT, caso núm., 1210]
2. *Ashapura Minechem Ltd* 480 B.R. 129 (S.D.N.Y. 2012)
3. *In re Atlas Shipping A/S* 404 B.R. 726 (Bankr. S.D.N.Y. 2009)
4. *In re Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund, Ltd* 389 B.R. 325 (S.D.N.Y. 2008)
[CLOUT, casos núms. 760, 794]
5. *In re Betcorp Ltd (in liquidation)* 400 B.R. 266 (Bankr. D. Nev. 2009)
[CLOUT, caso núm. 927]
6. *In re British American Ins. Co. Ltd* 425 B.R. 884 (Bankr. S.D.Fla. 2010)
[CLOUT, caso núm. 1005]
7. *Re Chow Cho Poon (Private) Limited* (2011) NSWSC 300 (15 de abril de 2011) [CLOUT, caso núm. 1218]
8. *Re Cinram International Inc* 2012 ONSC 3767 (Ont. SCJ [Commercial List])
[CLOUT, caso núm. ...]
9. *In re Ephedra Products Liability Litigation* 349 B.R. 333 (S.D.N.Y. 2006)
[CLOUT, caso núm. 765]
10. *Re Eurofood IFSC Ltd* [2006] Ch 508 (ECJ)
11. *In re Fairfield Sentry Ltd* 2011 WL 4357241
12. *Fogarty v Petroquest Resources Inc. (In re Condor Ins. Ltd)* 601 F.3d 319, (5th Cir. 2010)
[CLOUT, casos núms. 928, 1006]
13. *Gainsford, in the matter of Tannenbaum v Tannenbaum* (2012) FCA 904
[CLOUT, caso núm. 1214]
14. *In re Gerova Financial Group, Ltd.* 482 B.R. 86 (Bankr. S.D.N.Y. 2012)
15. *In re Gold & Honey, Ltd* 410 B.R. 357 (Bankr. E.D.N.Y. 2009)
[CLOUT, caso núm. 1008]
16. *Re HIH Casualty and General Insurance Ltd* [2005] EWHC 2125; first appeal
[2006] EWCA Civ 732;
McGrath v Riddle Segunda apelación [2008] UKHL 21
17. *Interdil, Srl* [2011] EUECJ C-396/09, [2012] Bus LR 1582
18. *Re Lightsquared LP* 2012 ONSC 2994 (Ont. SCJ [Commercial List])
[CLOUT, caso núm. 1204]

19. *Massachusetts Elephant & Castle Group, Inc.* 2011 ONSC 4201 (Ont. SCJ [Commercial List])
[CLOUT, caso núm. 1206]
20. *In re Metcalfe & Mansfield Alternative Investment* 421 BR 685 (Bankr. S.D.N.Y. 2010)
[CLOUT, caso núm. 1007]
21. *Millennium Global Emerging Credit Master Fund Limited et al* District Ct 11 Civ. 7865 junio de 2012
22. *In re Ran* 607 F.3d. 1017 (5th Cit. 2010)
[CLOUT, caso núm. 929]
23. *Rubin v Eurofinance SA* [2012] UKSC 46
24. *In re Sivec Srl, as successor in liquidation to Sirz Srl* 476 B.R. 310 (Bankr. E.D. Okla 2012)
25. *SNP Boat Service, S.A. v. Hotel le St. James* 483 B.R. 776 (S.D. Fla. 2012)
26. *Stanford International Bank Ltd* [2010] EWCA Civ. 137
[CLOUT, caso núm. 1003]
27. *Think3* Caso núm. 1757 de 2012. Recurso de apelación de la orden de sobreseimiento de la petición de reconocimiento y asistencia respecto de procedimientos de insolvencia extranjeros y de un mandamiento de administración (Casos del tribunal de primera instancia núms. 3 y 5 de 2011 en el Tribunal del Distrito de Tokio)
28. *In re Juergen Toft* 453 B.R. 186 (Bankr. S.D.N.Y. 2011)
[CLOUT, caso núm. 1209]
29. *In the matter of Vitro S.A.B. de C.V.* 2012 WL 5935630
(5th Cir. 28 de noviembre de 2012)
30. *Williams v Simpson* [2011] B.P.I.R. 938 (Tribunal Superior de Nueva Zelanda, Hamilton, 17 de septiembre de 2010);

Williams v Simpson (no. 5) Tribunal Superior de Nueva Zelanda, Hamilton, 12 de octubre de 2010

1. *In re ABC Learning Centres Limited*⁶⁸

El deudor era la empresa matriz australiana de 38 filiales que habían sido propietarias y administradoras de guarderías infantiles en Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, el Canadá y los Estados Unidos de América. En noviembre de 2008, las juntas directivas del deudor y sus 38 filiales tomaron la decisión de que, puesto que las empresas probablemente habrían de quedar insolventes, debían someterse a administración voluntaria en Australia y se nombraron los respectivos

⁶⁸ 445 B.R 318 (Bankr. D. Del 2010) [CLOUT, caso núm. 1210].

administradores. La iniciación de la administración voluntaria incumplía las condiciones de determinados acuerdos de préstamo, y los prestamistas ejercieron los derechos que les correspondían en virtud de la Ley de sociedades de Australia en calidad de acreedores garantizados a nombrar administradores que representaran sus intereses e iniciaran procedimientos de administración judicial. En junio de 2010, algunos de los acreedores resolvieron liquidar las empresas y los administradores fueron nombrados como liquidadores. Los procedimientos de administración judicial se realizaron paralelamente con la liquidación. En 2008 y 2009, se incoó en los Estados Unidos un litigio contra algunas de las empresas deudoras. En 2010, los liquidadores solicitaron que los procedimientos de liquidación se reconocieran en los Estados Unidos como procedimientos principales extranjeros. El tribunal dictaminó que los procedimientos de liquidación eran “procedimientos extranjeros” a los efectos del capítulo 15 y los reconoció como procedimientos extranjeros principales.

2. *Ashapura Minechem Ltd*⁶⁹

En octubre de 2011, el representante extranjero del deudor, una empresa minera e industrial con sede en Mumbai, solicitó que se reconocieran en los Estados Unidos de América los procedimientos entablados en la India y que estaban pendientes de resolución ante la Junta de Reconstrucción Financiera e Industrial, organismo autorizado para ejercer las funciones de tribunal administrativo en virtud de la Ley de empresas industriales en dificultades (disposiciones especiales) de 1985. El tribunal de los Estados Unidos consideró que aunque la legislación india en cuestión no preveía un mecanismo formal de participación de acreedores no garantizados, en la práctica la forma en que esos acreedores podían participar en los procedimientos demostraba que los procedimientos eran de carácter colectivo a los efectos del capítulo 11 § 101(23) [artículo 2 MLCBI] del Código de Leyes de los Estados Unidos. Aunque varios de los acreedores invocaron la excepción de orden público, el tribunal dictaminó que no habían cumplido el requisito de la carga de la prueba respecto de esa cuestión y que no podría denegarse por ese motivo el reconocimiento de la solicitud.

4. *In re Bear Stearns High-Grade Structured Credit Strategies Master Fund, Ltd*⁷⁰

Agréguese la siguiente oración al final del párrafo: “Esa decisión fue confirmada en apelación”.

7. *Re Chow Cho Poon (Private) Limited*⁷¹

En 2007, el Tribunal Superior de Singapur ordenó la liquidación de Chow Cho Poon (CCP), una empresa constituida en Singapur, con el argumento de que era justo y equitativo proceder a hacerlo (decisión que no se fundaba en la insolvencia del deudor). Tras haber descubierto que CCP poseía activos bancarios en Australia, el liquidador nombrado en Singapur presentó diversas solicitudes con respecto a esos activos, que el banco australiano del que se trataba se negó a atender, en espera de que en Australia se reconociera el nombramiento del liquidador. Si bien ese

⁶⁹ 480 B.R. 129 (S.D.N.Y. 2012).

⁷⁰ 389 B.R. 325 (S.D.N.Y. 2008) [CLOUT, casos núms. 760, 794].

⁷¹ (2011) NSWSC 300 (15 de abril de 2011) [CLOUT, caso núm. 1218].

reconocimiento se solicitó en virtud de otras leyes, el tribunal tuvo en cuenta el efecto de esas disposiciones en la Ley de insolvencia transfronteriza de 2008 [por la que se incorporaba la Ley Modelo en el derecho interno de Australia]. En particular, el tribunal consideró si el procedimiento incoado en Singapur era un procedimiento extranjero a tenor del artículo 2 de la Ley Modelo. El tribunal dictaminó que el liquidador era un representante extranjero con arreglo al artículo 2, que la liquidación era un procedimiento judicial y que los activos de la empresa estaban sujetos al control o supervisión de un tribunal extranjero. Quedaban por examinar dos cuestiones: si CCP era un deudor y si se trataba de un procedimiento que se ajustara a “una ley relativa a la insolvencia”. Aunque el tribunal señaló que su respuesta espontánea a esas dos preguntas era negativa, el examen de las decisiones de tribunales de Inglaterra (*Stanford International Bank Ltd*) y los Estados Unidos (*Betcorp* y *ABC Learning*) lo llevaban a concluir que había claros fundamentos que permitían aseverar que “la Ley de empresas de Singapur en su conjunto, o al menos la totalidad de las disposiciones relativas a la disolución, podría catalogarse como “una ley relativa a la insolvencia”, aunque la disolución de que se trataba hubiera sido ordenada basándose únicamente en que era justa y equitativa y, al parecer, sin que hubiera ninguna conclusión (explícita o implícita) de insolvencia”. Respecto de la segunda cuestión, el Tribunal señaló que en ninguno de los fallos examinados se prestaba atención por separado a la cuestión de si la empresa sujeta a disolución se podría describir adecuadamente como un “deudor”, dado que al parecer a cada tribunal le bastaba fundamentar su labor en el hecho de que una entidad sometida a un “procedimiento extranjero” quedaba incluida, por ese motivo únicamente, dentro del concepto pertinente de “deudor”.

8. *Re Cinam International Inc*⁷²

El Grupo Cinram era una empresa de duplicación y distribución de discos compactos y videodiscos digitales que mantenía operaciones en América del Norte y Europa. Tras experimentar dificultades financieras, varias entidades del Grupo constituidas en el Canadá entablaron procedimientos en ese país en los que solicitaban amplias medidas cautelares que les permitieran poner en práctica diversos planes de reestructuración, así como la autorización para que una de las entidades deudoras actuara como representante extranjero para diligenciar el reconocimiento del procedimiento canadiense en los Estados Unidos. Además de las entidades constituidas en el Canadá, el Grupo incluía entidades constituidas en los Estados Unidos y en Europa, aunque estas no hacían parte del procedimiento. Las partes en el procedimiento canadiense alegaron que el centro de los principales intereses del Grupo era el Canadá, presentando extensas pruebas para apoyar esa reclamación. El tribunal inició el procedimiento y otorgó las medidas solicitadas. Con respecto a la cuestión del centro de los principales intereses, el tribunal esbozó en su orden las pruebas que habían proporcionado los deudores canadienses, señalando que lo hacía a efectos de información únicamente. El tribunal afirmó que reconocía claramente que era función del tribunal ante el que se recurría -en este caso, el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos del Distrito de Delaware- determinar la localización del centro de los principales intereses y decidir si el procedimiento canadiense es un “procedimiento principal extranjero” a los efectos del capítulo 15 del Código de Quiebras de los Estados Unidos.

⁷² 2012 ONSC 3767 (Ont. SCJ [Commercial List]).

11. *In re Fairfield Sentry Ltd*⁷³

Agréguese la siguiente oración al final del párrafo: “La decisión fue confirmada en apelación ante el Tribunal del Distrito y ha sido de nuevo recurrida”.

13. *Gainsford, en la cuestión de Tannenbaum v Tannenbaum*⁷⁴

Los representantes sudafricanos de la insolvencia del Sr. Tannenbaum, un ciudadano sudafricano que se había trasladado a Australia en 2007, solicitaron que se reconociera en Australia el procedimiento iniciado en Sudáfrica y diversas órdenes relativas al examen de los negocios del deudor y su esposa y otras personas y entidades especificadas. El tribunal examinó lo que constituiría la residencia habitual del deudor a los efectos de la Ley de insolvencia transfronteriza, concretamente sus artículos 17 2) a) y 16 3) [artículos 17 2) a) y 16 3) de la Ley Modelo de la CNUDMI], tomando nota de la decisión adoptada en el caso *Williams c. Simpson* (véase más adelante) y de la interpretación que se hacía de ese concepto en la *Convención de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de niños*. El tribunal formuló dos observaciones: en primer lugar, la aplicación de la expresión “residencia habitual” permitía tener en cuenta una amplia diversidad de circunstancias que determinan el lugar en que se afirma que esa persona reside y si esa residencia se describe como residencia habitual. En segundo lugar, las intenciones que tenga o haya tenido la persona de que se trate a menudo influirán en el peso que se atribuye a circunstancias particulares, como la duración de los vínculos de la persona con un lugar concreto de residencia. Puesto que el Sr. Tannenbaum había decidido deliberadamente abandonar Sudáfrica en 2007 y había vivido y trabajado en Australia desde ese año y tenía su residencia habitual en este último país, el hecho de que conservara su ciudadanía sudafricana y no hubiese iniciado gestiones para inscribirse en el registro electoral australiano no era un factor determinante. Dado que el deudor no era residente habitual de Sudáfrica ni contaba con un establecimiento en este país, el procedimiento extranjero no podía reconocerse ni como procedimiento principal ni como procedimiento no principal. La medida solicitada se otorgó en virtud de otras leyes aplicables.

14. *Gerova Financial Group, Ltd*⁷⁵

Ambas entidades de Gerova estaban registradas en las Bermudas. Después de que un analista de valores publicó un informe en el que afirmaba que Gerova era de hecho un esquema Ponzi, Gerova fue demanda en los Estados Unidos y posteriormente terminó todos sus negocios antes de mayo de 2011. En octubre de 2011, tres acreedores solicitaron la iniciación de un procedimiento de insolvencia en las Bermudas. El procedimiento se suspendió a solicitud de Gerova, que logró llegar a una conciliación respecto de las demandas de dos de los acreedores e impugnó con éxito las demandas del tercero. Un cuarto acreedor asumió la función de demandante y presentó una petición enmendada, que el tribunal declinó suspender o desestimar. Sin embargo, le ofreció a Gerova la oportunidad de reembolsar en su totalidad la deuda del cuarto acreedor. Al no haberlo hecho, el tribunal ordenó la iniciación de un procedimiento de insolvencia contra las dos entidades de Gerova en

⁷³ 2011 WL 4357241 (S.D.N.Y., 16 sept. 2012).

⁷⁴ (2012) FCA 904 [CLOUT, caso núm. 1214].

⁷⁵ 482 B.R. 86 (Bankr. S.D.N.Y. 2012).

julio y agosto de 2012. Los liquidadores solicitaron el reconocimiento en los Estados Unidos de procedimiento iniciado en las Bermudas; en ese momento estaba pendiente un recurso de apelación contra la orden dictada en julio por el tribunal de las Bermudas. Varios acreedores objetaron el reconocimiento alegando que a) era innecesario, entre otras cosas porque era objetado por un número considerable de acreedores, b) la orden de iniciación era objeto de apelación, y c) por esas razones al reconocimiento se aplicaría la excepción de orden público prevista en el capítulo 11 del Código de Leyes de los Estados Unidos § 1506 [artículo 6 de la Ley Modelo de la CNUDMI]. El tribunal dictaminó que los procedimientos entablados en las Bermudas constituían procedimientos principales extranjeros, que no había ninguna disposición en el artículo § 1507 del Código de Quiebras [artículo 7 de la Ley Modelo de la CNUDMI] que condicionara el reconocimiento a un análisis de la relación costo-beneficio o a la aprobación de la mayoría de los acreedores; que correspondía al tribunal de las Bermudas decidir si correspondía iniciar el procedimiento y no era competencia del tribunal ante el que se recurriera condicionar el reconocimiento a un nuevo examen de esa necesidad; que en la redacción del artículo § 1517 [artículo 17 de la Ley Modelo de la CNUDMI] no había nada que estipulara que la decisión del tribunal de las Bermudas fuese definitiva o inapelable y puesto que la orden del tribunal de las Bermudas era suficiente para que los liquidadores pudieran asumir sus funciones, el artículo § 1518 [artículo 18 de la Ley Modelo de la CNUDMI] requeriría que los liquidadores notificaran al tribunal estadounidense si esa orden era revocada en apelación; y que en el presente caso no había nada que constituyera una transgresión de una cuestión de importancia fundamental que justificara invocar la excepción por razones de orden público.

15. *In re Gold & Honey, Ltd*⁷⁶

En julio de 2008 el prestamista principal del deudor entabló en Israel un procedimiento de administración judicial, pero debido a que se interpusieron ciertos acontecimientos, el tribunal israelí denegó el nombramiento de un administrador judicial. En septiembre de 2008 se abrió un procedimiento de reorganización en los Estados Unidos y se notificó de ello al prestamista principal del deudor. No obstante la iniciación del procedimiento en los Estados Unidos y la paralización automática a que dio lugar esa iniciación, el prestamista principal insistió en su solicitud de que se nombrara un administrador judicial en el tribunal israelí, argumentando que la paralización automática no se aplicaba a sus actuaciones ni a su intento de hacer que se nombrara un administrador judicial. En octubre de 2008, el tribunal estadounidense dictaminó, a solicitud del deudor y basándose en una audiencia en la que estuvo representado el prestamista principal, que la paralización automática se aplicaba a los bienes del deudor donde quiera que estuviesen localizados e independientemente de quien estuviera en posesión de ellos. Aunque el tribunal no llegó a considerar la cuestión de si la paralización se aplicaba concretamente a la administración judicial en Israel o de si tenía jurisdicción *in personam* sobre el prestamista principal, le notificó a este último que en caso de que decidiera seguir adelante con el procedimiento de administración judicial en Israel, lo haría a su propio riesgo. El prestamista principal insistió en su solicitud de administración judicial y, a fines de octubre de 2008, el tribunal israelí determinó que tenía

⁷⁶ 410 B.R. 357 (Bankr. E.D.N.Y. 2009) [CLOUT, caso núm. 1008].

jurisdicción y nombró en noviembre de 2008 administradores judiciales para liquidar los bienes del deudor en Israel a pesar del procedimiento en curso en los Estados Unidos y de la aplicación de la paralización en todo el mundo. A principios de enero de 2009, el prestamista principal solicitó una orden del tribunal estadounidense que rescindiera la paralización automática con respecto a la administración judicial israelí o sobreseyera el procedimiento de insolvencia entablado en los Estados Unidos. A fines de enero de 2009 los administradores de la insolvencia israelíes solicitaron el reconocimiento del procedimiento a su cargo en Nueva York para poder transferir los bienes situados en esa ciudad a Israel para su disposición en el procedimiento israelí. El tribunal de los Estados Unidos denegó el reconocimiento y dictaminó: a) que los representantes israelíes no habían cumplido obligación de probar que el procedimiento israelí era un procedimiento colectivo y que los bienes y negocios del deudor estaban sujetos al control y la supervisión de un tribunal extranjero con arreglo a la definición dada en el título 11 § 101 (23) del Código de las Leyes de los Estados Unidos [artículo 2 a) de la Ley Modelo de la CNUDMI]; b) que los representantes israelíes habían sido nombrados en violación de la paralización automática; y c) que no se había cumplido el umbral necesario para establecer la excepción de orden público enunciada en el título 11 § 1506 del Código de las Leyes de los Estados Unidos [artículo 6 de la Ley Modelo de la CNUDMI].

17. *Interedil Srl*⁷⁷

La empresa *Interedil* estuvo registrada en Italia hasta julio de 2001, año en que trasladó su domicilio social al Reino Unido y fue eliminada del registro de empresas de Italia y agregada al registro de empresas del Reino Unido. En el momento del traslado, el grupo británico Canopus adelantaba el proceso de adquisición de *Interedil* y unos pocos meses más tarde la titularidad sobre los bienes que poseía *Interedil* en Italia fue transferida a otra empresa británica como parte de dicha adquisición. En 2002, *Interedil* fue suprimida del registro de empresas del Reino Unido. En octubre de 2003 la empresa *Intesa* solicitó la iniciación de un procedimiento de insolvencia contra *Interedil* en Bari (Italia). *Interedil* impugnó la solicitud alegando que solo los tribunales del Reino Unido gozaban de la competencia requerida y solicitó al tribunal superior de Italia un fallo sobre la jurisdicción. Sin esperar a ese fallo, el tribunal de Bari inició el procedimiento en mayo de 2004. En junio de 2004, *Interedil* radicó una apelación contra esa orden. En mayo de 2005 el tribunal superior italiano pronunció un fallo sobre la primera solicitud, en el que dictaminaba que el tribunal de Bari tenía jurisdicción basándose en que la presunción de que el centro de los principales intereses de un deudor es su domicilio social podía rebatirse, en ese caso gracias a que la empresa tenía en Italia bienes inmuebles, un acuerdo de arrendamiento de dos hoteles y un contrato con un banco, y al hecho de que el registro de empresas italianas no había sido notificado del traslado del domicilio social. El tribunal de Bari remitió luego varias cuestiones al Tribunal Europeo de Justicia para que se pronunciase al respecto con carácter prejudicial. Con respecto a la cuestión relativa a la refutación de la presunción del domicilio social, el Tribunal dictaminó que el centro de los principales intereses de un deudor debe determinarse atribuyendo mayor importancia al lugar de su administración central que deberá establecerse mediante factores objetivos verificables por terceros. Cuando la administración, que incluye la adopción de

⁷⁷ [2011] EUECJ C-396/09, [2012] Bus LR 1582.

decisiones de gestión y la supervisión, se lleva a cabo en el mismo lugar en que se encuentra el domicilio social de forma verificable por terceros, la presunción no puede rebatirse. Cuando la administración central no se encuentra en el mismo lugar del domicilio social, los factores citados en el caso en cuestión no bastaban para rebatir la presunción a menos de que una evaluación completa de los factores permita establecer, de manera verificable por terceros, que el centro real de gestión y supervisión se encuentra en ese otro lugar. El Tribunal pasó luego a dictaminar que cuando el domicilio social de una empresa deudora es trasladado antes de que se solicite la iniciación del procedimiento de insolvencia, se presume que el centro de los principales intereses es el lugar del nuevo domicilio social.

18. *Re Lightsquared LP*⁷⁸

El deudor era un grupo integrado por *Lightsquared* y unas 20 de sus filiales, 16 de las cuales estaban constituidas y tenían su sede en los Estados Unidos, tres estaban constituidas en diversas provincias del Canadá y una estaba constituida en las Bermudas. Cada una de ellas inició procedimientos de reorganización voluntaria en los Estados Unidos y en mayo de 2012 *Lightsquared*, como representante extranjero del deudor, solicitó que se reconociera en el Canadá como procedimiento principal extranjero el procedimiento entablado en los Estados Unidos, y que se reconocieran además determinadas órdenes del tribunal estadounidense y determinadas medidas accesorias. El tribunal canadiense examinó los hechos concernientes a la organización y estructura de las entidades deudoras a fin de determinar la ubicación del centro de los principales intereses de las entidades canadienses. El juez concluyó que, en caso de que no bastara con la simple presunción respecto del domicilio social, los factores principales que se exponen a continuación, considerados en su conjunto, tenderían a indicar que el lugar en que se inició el procedimiento es el centro de los principales intereses del deudor, a saber: i) si el lugar es fácilmente verificable por los acreedores; ii) si se trata del lugar en que el deudor tiene sus principales bienes o realiza sus principales operaciones; y iii) si ese es el lugar en que se lleva a cabo la administración de los negocios del deudor. Basándose en esos factores, el juez concluyó que el centro de los principales intereses de las entidades canadienses se encontraba en los Estados Unidos, reconoció el procedimiento extranjero como procedimiento extranjero principal, reconoció las órdenes dictadas por el tribunal estadounidense y otorgó las medidas accesorias solicitadas.

19. *Massachusetts Elephant & Castle Group, Inc. (Re)*⁷⁹

Los deudores explotaban bajo franquicia en los Estados Unidos y el Canadá una serie de pubs de estilo británico con servicio completo. En junio de 2011 se inició en los Estados Unidos un procedimiento en virtud del capítulo 11 contra los deudores y se solicitó el reconocimiento de dicho procedimiento en el Canadá. Con excepción de tres miembros del grupo que estaban constituidos en el Canadá, las 11 empresas deudoras restantes estaban constituidas en los Estados Unidos de América. El tribunal canadiense examinó los factores pertinentes para determinar la ubicación del centro de los principales intereses de las tres empresas canadienses, y llegó a la conclusión de que los tres factores siguientes suelen ser importantes: a) la ubicación de la sede del deudor o del lugar donde se desempeñan las funciones administrativas

⁷⁸ 2012 ONSC 2994 (Ont. SCJ [Commercial List]) [CLOUT, caso núm. 1204].

⁷⁹ 2011 ONSC 4201; (2011) 81 C.B.R. (5th) [CLOUT, caso núm. 1206].

principales; b) el lugar donde se encuentran los directivos de la empresa deudora; c) el lugar que los acreedores importantes reconocen como el centro de operaciones del deudor. Si bien otros factores pueden tener aplicación en casos concretos, el tribunal fue de la opinión de que estos deberían considerarse de importancia secundaria y solo en la medida en que se relacionaran con los tres factores principales o los reforzaran. Al aplicar esos factores a los hechos en examen, el tribunal hizo notar que la oficina principal de todos los deudores sujetos al capítulo 11 se encontraba en Boston; que el grupo funcionaba como negocio estadounidense integrado cuyo proceso de adopción de decisiones estaba centralizado en su totalidad en la sede central de Boston; y que todos los miembros del equipo de administración central del deudor se encontraban en Boston, al igual que los recursos humanos y las funciones de contabilidad y financiación y demás funciones administrativas y de tecnología de la información. El tribunal concluyó que el centro de los principales intereses de las empresas canadienses se encontraba en Boston, reconoció el procedimiento estadounidense como procedimiento extranjero principal y otorgó medidas adicionales a las medidas obligatorias otorgables a raíz del reconocimiento, reconociendo ante todo determinadas órdenes del tribunal estadounidense dictadas en el procedimiento relacionado con el capítulo 11.

21. *Millennium Global Emerging Credit Master Fund Limited et al*⁸⁰

Los dos deudores (un fondo subordinado y un fondo principal) eran fondos de inversión “offshore” que invertían en títulos de deuda soberana y deuda empresarial de emisores de países en desarrollo. Ambos fondos habían sido constituidos en las Bermudas, el fondo subordinado en 2006 y el fondo principal en 2007. Tras la constitución del fondo principal, el fondo subordinado le transfirió prácticamente la totalidad de su activo, a cambio de derechos de propiedad del 97% en el fondo principal. En octubre de 2008, los fondos experimentaron graves problemas de corriente de efectivo y no pudieron cumplir diversas peticiones de reposición del margen de garantía. Los directores del fondo solicitaron que se iniciaran procedimientos de liquidación en las Bermudas, procedimientos que el tribunal inició en 2009 y nombró a los representantes extranjeros liquidadores de ambos fondos. Los liquidadores solicitaron a varias entidades con sede en los Estados Unidos la proposición oficiosa de pruebas, pero cuando los intentos de negociar la presentación oficiosa de documentos no dieron resultado, solicitaron el reconocimiento del procedimiento de las Bermudas en los Estados Unidos de América. En primera instancia, el tribunal estadounidense dictaminó que el centro de los principales intereses del deudor debería determinarse mediante remisión a la fecha de iniciación del procedimiento extranjero y que el centro de los principales intereses de ambos deudores en esa fecha eran las Bermudas. El fallo sobre la ubicación del centro de los principales intereses fue objeto de impugnación basándose en el argumento de que una serie de hechos relacionados con la estructura de los negocios de los deudores apuntaban hacia el Reino Unido como el centro de los principales intereses. El fallo con respecto a la fecha no fue impugnado. En apelación, el tribunal evaluó las circunstancias en función de cinco factores (la ubicación de la sede del deudor, la ubicación del personal directivo de los negocios del deudor, la ubicación de los bienes principales del deudor, la ubicación de la

⁸⁰ District Ct 11 Civ. 7865 (LBS) junio de 2012.

mayoría de los acreedores del deudor que se verían afectados por el caso, y la jurisdicción cuya ley sería aplicable a la mayoría de las controversias), y de las expectativas de acreedores y otros terceros interesados en lo concerniente a la verificabilidad del centro de los principales intereses de los fondos. El tribunal concluyó que aunque algunos de esos factores podrían respaldar el argumento de que el centro de los principales intereses se encontraba en el Reino Unido, el peso decisivo de las pruebas se inclinaba a favor de las Bermudas como centro de los principales intereses de los deudores, independientemente de que dicho centro se determinara por referencia a la fecha de iniciación del procedimiento extranjero o la fecha de presentación de la solicitud con arreglo al capítulo 15.

23. *Rubin v Eurofinance SA*⁸¹

Los representantes de un procedimiento de insolvencia iniciado en los Estados Unidos en 2007 contra The Consumers Trust solicitaron el reconocimiento de ese procedimiento en Inglaterra con arreglo al Reglamento de la insolvencia transfronteriza de 2006, que dio aplicación a la Ley Modelo en Gran Bretaña, así como la ejecución de un fallo del tribunal de los Estados Unidos que declaraba a Eurofinance responsable de las deudas del The Consumers Trust, que era un fondo empresarial, reconocido como persona jurídica conforme a la legislación de los Estados Unidos. En 2009, el tribunal inglés reconoció el procedimiento de insolvencia extranjero como procedimiento principal, pero desestimó la solicitud de ejecución del fallo. En la primera apelación contra la desestimación de la solicitud de ejecución, el tribunal falló a favor del apelante, llegando a la conclusión de que las reglas ordinarias para ejecutar o dejar de ejecutar fallos extranjeros *in personam* no se aplicaban a los procedimientos de insolvencia y que los mecanismos existentes en los procedimientos de insolvencia para entablar acciones contra terceros en beneficio colectivo de todos los acreedores eran esenciales al carácter colectivo de la insolvencia y no meras cuestiones procesales secundarias. Por consiguiente, las órdenes contra Eurofinance eran parte del procedimiento de insolvencia y afectaban el régimen de su ejecución colectiva. Como tales, las órdenes no estaban sujetas a las reglas ordinarias de derecho internacional privado que impiden la ejecución de fallos porque los demandados no están sujetos a la jurisdicción del tribunal extranjero. En una segunda apelación ante el Tribunal Supremo, este rechazó el criterio del tribunal de apelaciones y desestimó la solicitud de ejecución del fallo. El tribunal dictaminó que las órdenes estaban sujetas a las normas ordinarias del derecho internacional privado y que no se cumplía ninguna de las condiciones de ejecución previstas en el *common law*. El Tribunal consideró asimismo que los artículos 21 y 25 de la Ley Modelo trataban cuestiones de procedimiento y no facultaban implícitamente a los tribunales a ejecutar un fallo de insolvencia extranjero contra un tercero.

24. *In re Sivec*⁸²

En el caso *Sivec*, el reconocimiento en los Estados Unidos de América de un mandato de reorganización dictado en Italia como procedimiento principal extranjero y la modificación de la paralización automática a fin de permitir el litigio en los Estados Unidos de dos demandas de posible compensación. El litigio

⁸¹ [2010] EWCA Civ. 895.

⁸² 476 B.R. 310 (Bankr. E.D. Okla. 2012).

cristalizó en un fallo a favor del deudor italiano en la primera demanda y un fallo a favor del acreedor estadounidense (el acreedor) en la segunda. El acreedor solicitó de modo que fuera posible luego medidas de amparo de la paralización automática para la compensación entre las dos sumas objeto de las sentencias, y el deudor italiano solicitó la ejecución del procedimiento de reorganización, que, al parecer, requeriría que el acreedor abonara la suma establecida en el primer fallo, pero no lo facultaba para demandar en el caso italiano respecto del segundo fallo, puesto que no había presentado una demanda a tiempo (alegó que nunca había recibido una notificación apropiada). El tribunal estadounidense dictaminó que no reconocería el principio de la cortesía internacional respecto del procedimiento italiano, dado que el deudor italiano “no había suministrado información relativa a la ley italiana, o a la situación del caso de quiebra en Italia ni había cumplido con la carga de la prueba que le correspondía al solicitar el reconocimiento de la cortesía”. El tribunal expresó particular preocupación por la falta de notificación al acreedor, concluyó que se echaban de menos elementos básicos del debido proceso y que no se habían protegido los intereses del acreedor estadounidense. En ejercicio de lo que denominó “un amplio margen de discreción para configurar las medidas apropiadas en este caso”, el tribunal dictaminó que al acreedor se le tenía que reconocer la exención de la paralización para ejercer sus derechos de compensación o resarcimiento con arreglo a la ley de los Estados Unidos.

25. *SNP Boat Service, S.A. v. Hotel le St. James*⁸³

SNP Boat Service, una empresa francesa, celebró un contrato con un tercero que exigía que aceptara una permuta de bienes de propiedad de *St. James*, una empresa canadiense. Hubo desacuerdo en cuanto a la ejecución del contrato y la diferencia terminó en litigios en Francia y el Canadá. *SNP* inició en Francia un procedimiento de insolvencia, en el que *St. James* radicó una demanda. En el litigio entablado en el Canadá, el tribunal emitió un fallo de incumplimiento a favor de *St. James*, que solicitó luego que el fallo se ejecutara sobre bienes de *SNP* en la Florida. Antes de que pudieran venderse los bienes, el representante extranjero solicitó el reconocimiento del procedimiento francés en los Estados Unidos. Se otorgó el reconocimiento y se ordenó la paralización de la venta de bienes en la Florida. Los bienes fueron posteriormente entregados al representante extranjero aunque se prohibió que fueran sacados del territorio bajo jurisdicción del tribunal y su venta quedó sujeta a la aprobación del tribunal. El representante extranjero solicitó luego que se aprobara la repatriación de los bienes a Francia para disponer de ellos con arreglo al procedimiento francés. *St. James* objetó la solicitud alegando, entre otras cosas, que en el procedimiento francés sus intereses no se verían “suficientemente protegidos”. El tribunal inferior ordenó la proposición de pruebas para determinar si los intereses de *St. James* en calidad de acreedor quedaban suficientemente protegidos en el procedimiento francés, y en último término denegó la solicitud de repatriación, dictaminó que los bienes se entregaran al funcionario local competente y desestimó el procedimiento iniciado con arreglo al capítulo 15. En apelación, el tribunal dictaminó que no estaba impedido de cerciorarse de que los intereses de acreedores extranjeros en general estaban suficientemente protegidos antes de autorizar el envío de los bienes a la jurisdicción extranjera. Sin embargo, descartó la idea de que estaba facultado para iniciar averiguaciones sobre el tratamiento

⁸³ 483 B.R. 776 (S.D. Fla. 2012).

individual que recibiría el acreedor en Francia, y concluyó que “un tribunal de quiebras no goza de competencia para investigar si los intereses de un acreedor determinado están suficientemente protegidos en todo procedimiento extranjero concreto”. El tribunal llegó a la conclusión de que tanto la orden de proposición de pruebas como la denegación de la solicitud de repatriación de los bienes constituían un abuso de la facultad discrecional y devolvió el caso para que se iniciara un nuevo procedimiento.

27. *Think3*⁸⁴

El deudor (Think3.Inc), empresa sucesora de diversas empresas establecidas originalmente en Italia y en los Estados Unidos de América, estaba constituida en los Estados Unidos y tenía una sucursal en Italia y filiales en seis países, entre ellos Italia y el Japón. Al procedimiento de insolvencia iniciado en Italia en abril de 2011, siguió el procedimiento con arreglo al capítulo 11 en los Estados Unidos en mayo de 2011. El 1 de agosto de 2011, se solicitó el reconocimiento del procedimiento italiano en los Estados Unidos. El 11 de agosto de 2011, se solicitó el reconocimiento del procedimiento estadounidense en el Japón, y reconocimiento que se otorgó el mismo día, junto con determinadas medidas complementarias. En octubre de 2011 se solicitó también el reconocimiento del procedimiento italiano en el Japón, con el argumento de que el “principal lugar de negocios” del deudor (que es la expresión utilizada en la ley japonesa por la que se incorpora la Ley Modelo al derecho interno y que se considera que tiene en el fondo el mismo significado que la expresión “centro de los principales intereses”) se encontraba en Italia y no en los Estados Unidos⁸⁵. En la determinación de los factores que debería tenerse en cuenta respecto del principal lugar de negocios del deudor, el tribunal de primera instancia examinó la labor que adelantaba la CNUDMI de revisión de la Guía de incorporación de la Ley Modelo en el derecho interno. El tribunal dictaminó que, si bien era procedente tener en cuenta todos los diversos factores que habían planteado diferentes tribunales de todo el mundo, el énfasis se debería poner en el lugar donde se cumplen las funciones de la oficina central, los bienes básicos, el lugar efectivo de los negocios del deudor y el personal directivo de los negocios del deudor, y si esa ubicación era verificable para los acreedores. Con respecto al momento, el tribunal fue de la opinión de que el momento se debería determinar por referencia al momento en que se había registrado el primero de los procedimientos de insolvencia relacionados con el deudor o en que había comenzado ese procedimiento. Tras haber examinado los complejos antecedentes recientes del deudor a la luz de los diversos factores que era preciso tener en cuenta, el tribunal concluyó que el principal lugar de negocios del deudor se encontraba en los Estados Unidos. Esa decisión fue confirmada en apelación.

⁸⁴ Caso núm. 1757 de 2012. Recurso de apelación contra una orden de denegación de una solicitud de reconocimiento y asistencia respecto de un procedimiento de insolvencia extranjero y una orden de administración (Numeración del tribunal de primera instancia: casos núms. 3 y 5 de 2011 del Tribunal del Distrito de Tokio) que se puede consultar en inglés y en japonés en www.insol.org/page/304/japan.

⁸⁵ Véase la nota de pie de página 157 del párr. 102G.

28. *In re Dr. Juergen Toft*⁸⁶

El deudor, a quien se le había abierto un procedimiento de insolvencia en Alemania, se había negado a cooperar con el representante extranjero, había ocultado sus bienes y se había trasladado a un país desconocido. El representante extranjero había obtenido una orden de interceptación del correo, aplicable al correo postal y al correo electrónico intercambiado en el marco del procedimiento alemán, así como el reconocimiento *ex parte* del procedimiento alemán y la ejecución en Inglaterra de la orden de interceptación del correo dictada en Alemania. El representante extranjero solicitó el reconocimiento del procedimiento iniciado en Alemania en los Estados Unidos, junto con medidas *ex parte* para ejecutar la orden de interceptación del correo en los Estados Unidos y obligar a determinados proveedores de servicio a revelar y entregar al representante extranjero todos los correos electrónicos del deudor almacenados en ese momento en sus servidores, así como los que recibiera en el futuro. Basándose en que esa medida no sería otorgable a un representante de la insolvencia en virtud de la ley estadounidense y que contravendría determinar disposiciones legislativas relativas a la privacidad y la escucha telefónica, lo cual podría crear una responsabilidad penal, el tribunal denegó la medida solicitada por ser manifiestamente contraria a la normativa de orden público de los Estados Unidos con arreglo al Título 11 § 1506 del Código de las Leyes de los Estados Unidos [artículo 6 de la Ley Modelo de la CNUDMI]. La denegación se dictó a reserva del derecho del representante extranjero a solicitar el reconocimiento tras haber suministrado la notificación pertinente requerida en virtud de la ley de los Estados Unidos.

29. *In the matter of Vitro S.A.B. de C.V.*⁸⁷

Vitro era una sociedad de cartera de inversiones que, junto con sus filiales, era el mayor fabricante de vidrio de México. Entre 2003 y 2007, Vitro tomó en préstamo una suma considerable, principalmente de inversionistas de los Estados Unidos, según se desprendía de tres series de pagarés no garantizados, con diversas fechas de vencimiento en 2012, 2013 y 2017 y garantizados por prácticamente todas las filiales de Vitro. Las garantías, que se regían por la ley de Nueva York, estipulaban que los garantes no quedarían liberados, exonerados o afectados de alguna otra manera por ningún arreglo o liberación resultante de cualquier proceso de insolvencia, reorganización o quiebra que afectara a Vitro y que las controversias se someterían a resolución judicial en Nueva York. En 2008, Vitro anunció su intención de reestructurar su deuda y dejó de abonar pagos por concepto de los pagarés no garantizados. En 2009, Vitro concertó arreglos con Fintech Investments Ltd., uno de sus mayores acreedores cuyo resultado fue que Vitro generó una cuantiosa deuda intercorporativa. La deuda no fue revelada a los tenedores de los pagarés no garantizados hasta aproximadamente 300 días después de que se cerraran las transacciones, con lo cual estas venían a quedar fuera del período de sospecha de 270 días establecido en México, y durante el cual habrían sido sometidas a análisis complementario antes de que la empresa entrara en insolvencia. Aunque entre 2009 y 2010 Vitro inició varias rondas de negociaciones de reorganización, los acreedores rechazaron sus propuestas. En diciembre de 2010 Vitro presentó una solicitud en virtud de la Ley de reorganización de empresas de México. A pesar del

⁸⁶ 453 B.R. 186 (Bankr. S.D.N.Y. 2011) [CLOUT, caso núm. 1209].

⁸⁷ 2012 WL 5935630 (5th Cir., 28 Nov 2012).

rechazo inicial debido a que Vitro no pudo alcanzar el umbral requerido del 40% de aprobación de los acreedores necesario para respaldar la solicitud sin tener que recurrir a créditos intercorporativos, el tribunal mexicano aprobó la solicitud, pero la decisión fue revocada en apelación y Vitro fue declarada en quiebra en abril de 2011. Se negoció luego un plan de reorganización con los acreedores reconocidos (incluidos los tenedores de deuda intercorporativa), en el que se prevería, entre otras cosas, la anulación de los pagarés no garantizados y el cumplimiento de las obligaciones adeudadas por los garantes. El plan fue aprobado en último término con el porcentaje requerido de acreedores y el tribunal mexicano lo aprobó en febrero de 2012. Esa decisión de aprobación fue luego recurrida. Los acreedores que no estaban satisfechos con la reorganización trataron de cobrar de diversas maneras los pagarés no garantizados y las garantías. En una demanda entablada en Nueva York, el tribunal dictaminó que la ley de Nueva York se aplicaba a las garantías y que estaba prohibida la liberación, exoneración o modificación no consensuadas de las obligaciones inherentes de las garantías. En abril de 2011 se solicitó el reconocimiento en los Estados Unidos del procedimiento mexicano, reconocimiento que se otorgó finalmente como procedimiento principal extranjero. Esa decisión ha sido recurrida. En marzo de 2012, los representantes extranjeros de Vitro solicitaron diversas órdenes para la aplicación de medidas en los Estados Unidos, incluida la ejecución del plan de reorganización mexicano y un mandamiento judicial por el que se prohibían determinadas acciones en los Estados Unidos en contra de Vitro, pero las medidas solicitadas fueron denegadas. La decisión fue recurrida con el razonamiento de que el tribunal había cometido un error judicial al denegar la ejecución del plan porque modificaba obligaciones en materia de garantías de partes no deudoras. En apelación, el tribunal estadounidense confirmó la orden de reconocimiento del procedimiento mexicano y la orden de denegación de las medidas solicitadas basándose en que si bien, en circunstancias excepcionales, el tribunal podría en virtud del capítulo 15 hacer cumplir una orden de extinción de las obligaciones de partes no deudoras, Vitro no había demostrado la existencia de esas circunstancias excepcionales en el caso en cuestión.

Anexo II

Decisión de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y resolución 66/9 de la Asamblea General

[...]

V. GARANTÍAS REALES

A. Informe del Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales sobre la labor realizada en su 22º período de sesiones (Viena, 10 a 14 de diciembre de 2012)

(A/CN.9/764)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-8
II. Organización del período de sesiones	9-14
III. Deliberaciones y decisiones	15
IV. Inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles	16-80
A. Prefacio (A/CN.9/WG.VI/WP.52)	16
B. Introducción (A/CN.9/WG.VI/WP.52 y A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1, párrs. 1 a 39)	17-27
C. Creación y funciones del registro de garantías reales (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1, párrs. 40 a 55)	28-32
D. Acceso a los servicios del registro (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1, párrs. 56 a 61 y A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrs. 1 a 10)	33-39
E. Inscripción registral (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrs. 11 a 58)	40-53
F. Información sobre la inscripción registral (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.3, párrs. 1 a 56)	54-62
G. Información sobre la modificación o cancelación de una notificación (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párrs. 1 a 30)	63-74
H. Consultas (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párrs. 31 a 41)	75-78
I. Derechos de inscripción y de consulta (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párrs. 42 a 48)	79
J. Ejemplos de formularios de registro (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.6)	80
V. Labor futura	81

I. Introducción

1. En su período de sesiones actual, el Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) prosiguió su labor de preparación de un texto relativo a la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles, de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión en su 43º período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio

de 2010)¹. La Comisión adoptó su decisión en el entendimiento de que ese texto sería un complemento útil de la labor de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas y ofrecería a los Estados una orientación urgentemente requerida para la apertura y el funcionamiento de los registros de garantías reales².

2. En ese período de sesiones, la Comisión examinó una nota de la Secretaría (A/CN.9/702 y Add.1) y convino en que todas las cuestiones mencionadas en ella (incluidas la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles, una ley modelo sobre las operaciones garantizadas y las garantías reales sobre valores no depositados en poder de intermediarios) presentaban interés y debían mantenerse en su futuro programa de trabajo para su examen. No obstante, habida cuenta de los limitados recursos de que disponía, la Comisión acordó que debía concederse prioridad a la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles³.

3. En su 18º período de sesiones (Viena, 8 a 12 de noviembre de 2010) el Grupo de Trabajo inició su labor de preparación de un texto sobre la inscripción registral de notificaciones relativas a las garantías reales sobre bienes muebles, con el examen de una nota de la Secretaría titulada “Inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles” (A/CN.9/WG.VI/WP.44 y Add.1 y Add.2). En ese período de sesiones el Grupo de Trabajo adoptó la hipótesis de trabajo de que el texto revestiría la forma de una guía sobre la creación de un registro de garantías reales, se ajustaría al contenido de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (la “*Guía sobre las Operaciones Garantizadas*”) y, al mismo tiempo, tendría en cuenta los enfoques seguidos en los sistemas modernos de inscripción registral de garantías reales, tanto nacionales como internacionales (A/CN.9/714, párr. 13). Tras convenir en que la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* era coherente con los principios rectores enunciados en los textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico, el Grupo de Trabajo estudió también ciertas cuestiones dimanantes del empleo de las comunicaciones electrónicas en los registros de garantías reales con el fin de garantizar que, al igual que la *Guía*, el texto relativo a la inscripción registral fuese coherente con esos principios (A/CN.9/714, párrs. 34 a 47).

4. En su 19º período de sesiones (Nueva York, 11 a 15 de abril de 2011) el Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía para un registro de las garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.46 y Add.1 a Add.3). En ese período de sesiones se expresaron diversas opiniones sobre la forma y el contenido del texto que habría de prepararse (A/CN.9/719, párrs. 13 y 14), así como sobre la cuestión de si el texto debía presentarse en forma de reglamento modelo o de recomendaciones (A/CN.9/719, párr. 46).

5. En su 44º período de sesiones (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011), la Comisión insistió en la importancia de la labor del Grupo de Trabajo, habida cuenta en particular de los esfuerzos de los Estados por establecer un registro, así como de las posibles repercusiones beneficiosas que tendría el registro en la oferta y el precio del crédito. En cuanto a la forma y el contenido del texto que había de prepararse, la Comisión convino en que no era preciso modificar el mandato del Grupo de Trabajo,

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17* (A/65/17), párr. 268.

² *Ibid.*, párr. 265.

³ *Ibid.*, párrs. 264 y 273.

al que se confiaba la decisión sobre la forma y el contenido específicos del texto. Se convino además en que, en cualquier caso, la Comisión adoptaría la decisión final una vez que el Grupo de Trabajo hubiera concluido su labor y le hubiera presentado el texto⁴.

6. En su 20º período de sesiones (Viena, 12 a 16 de diciembre de 2011), el Grupo de Trabajo prosiguió su labor basándose en una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía para un registro de las garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.48/Add.3). El Grupo de Trabajo convino en que el texto debería adoptar la forma de una guía (el “proyecto de guía para un registro”) con un comentario y recomendaciones similares a los de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (A/CN.9/740, párr. 18). Además, se convino en que cuando en el proyecto de guía se ofrecieran opciones, se podrían incluir en un anexo ejemplos de reglas modelo. En cuanto a la presentación del texto, se acordó que el proyecto de guía se presentara como un texto aparte, independiente y amplio que estuviera en consonancia con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y que se titulara provisionalmente “Guía legislativa técnica para la aplicación de un registro de las garantías reales” (A/CN.9/740, párr. 30).

7. En su 21º período de sesiones (Nueva York, 14 a 18 de mayo de 2012), el Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía legislativa técnica relativa a la aplicación de un registro de las garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.50 y Add.1 y Add.2). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección relativa a la terminología y de las recomendaciones del proyecto de guía (A/CN.9/743, párr. 21). Además, el Grupo de Trabajo acordó que el proyecto de guía se concluyera y se sometiera a la aprobación de la Comisión en su 46º período de sesiones, previsto para 2013 (A/CN.9/743, párr. 73). El Grupo de Trabajo convino también en proponer a la Comisión que le encomendara el mandato de elaborar una ley modelo sobre las operaciones garantizadas y que se mantuviera en su futuro programa de trabajo el tema de las garantías reales sobre valores no depositados en poder de intermediarios, a fin de examinarlo en un ulterior período de sesiones (A/CN.9/743, párr. 76).

8. En su 45º período de sesiones (Nueva York, 25 de junio a 6 de julio de 2012) la Comisión expresó su gratitud al Grupo de Trabajo y le pidió que agilizará y concluyera su labor, de modo que el proyecto de guía se pudiera presentar para darle su aprobación final y adoptarlo en su 46º período de sesiones, que se celebraría en 2013⁵. Además, la Comisión convino en que, una vez que el Grupo de Trabajo hubiese concluido el proyecto de guía, emprendería la preparación de una ley modelo sobre las operaciones garantizadas, sencilla, breve y concisa, que se basara en las recomendaciones generales de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y se ajustara a todos los textos preparados por la CNUDMI en materia de operaciones garantizadas⁶. Asimismo, la Comisión acordó que, con arreglo a la decisión adoptada por ella en su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, se mantendría en el futuro programa de trabajo el tema de las garantías reales sobre valores no depositados en poder de intermediarios, entendidas como garantías distintas de las acreditadas en una cuenta de valores, a efectos de seguirlo examinando. Para ello, la

⁴ *Ibid.*, Sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 237.

⁵ *Ibid.*, Sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 100.

⁶ *Ibid.*, párr. 105.

Secretaría prepararía una nota en la que se enunciarían todas las cuestiones pertinentes, a fin de evitar duplicaciones o incoherencias con los textos preparados por otras organizaciones.

II. Organización del período de sesiones

9. El Grupo de Trabajo, que se compone de todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 22º período de sesiones en Viena del 10 al 14 de diciembre de 2012. Asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Brasil, Canadá, China, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, India, Israel, Italia, Japón, México, Nigeria, Noruega, Pakistán, República Checa, República de Corea, Tailandia, Turquía, Ucrania y Venezuela (República Bolivariana de).

10. Asistieron al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Arabia Saudita, Belarús, Bélgica, Brunei Darussalam, Chipre, Indonesia, Kuwait, Omán, Polonia, Qatar, República Dominicana, Suiza y Viet Nam. También asistieron al período de sesiones observadores de Palestina y de la Unión Europea.

11. Asistieron asimismo al período de sesiones observadores de las siguientes organizaciones internacionales:

a) *Sistema de las Naciones Unidas*: Banco Mundial;

b) *Organizaciones intergubernamentales*: Consejo de la Asamblea Interparlamentaria de Naciones Miembros de la Comunidad de Estados Independientes y Centro Europeo para la Paz y el Desarrollo;

c) *Organizaciones no gubernamentales internacionales invitadas por la Comisión*: American Bar Association (ABA), Asociación Europea de Estudiantes de Derecho, Centro Nacional de Investigaciones Jurídicas para el Libre Comercio Interamericano, Commercial Finance Association (CFA), Foro de Conciliación y Arbitraje Internacionales, International Federation of Film Distributors Association (FIAD), International Insolvency Institute (III).

12. El Grupo de Trabajo eligió la siguiente Mesa:

Presidenta: Sra. Kathryn SABO (Canadá)

Relator: Sr. Hiroo SONO (Japón)

13. El Grupo de Trabajo tuvo a su disposición los siguientes documentos: A/CN.9/WG.VI/WP.51 (Programa provisional anotado), A/CN.9/WG.VI/WP.52 y Add.1 a Add.6 (Proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales).

14. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:

1. Apertura del período de sesiones y programación de las reuniones.
2. Elección de la Mesa.
3. Aprobación del programa.
4. Inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles.

5. Otros asuntos.
6. Aprobación del informe.

III. Deliberaciones y decisiones

15. El Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.52 y Add.1 a Add.6). Las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo se reseñan más adelante en los capítulos IV y V. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del proyecto de guía y pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada del texto que reflejara sus deliberaciones y decisiones.

IV. Inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles

A. Prefacio (A/CN.9/WG.VI/WP.52)

16. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del prefacio del proyecto de guía sobre el registro en el entendimiento de que se actualizaría después de los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo y de la Comisión para recoger los resultados de sus respectivas deliberaciones.

B. Introducción (A/CN.9/WG.VI/WP.52 y A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1, párrs. 1 a 39)

17. El Grupo de Trabajo aprobó sin modificaciones el contenido de la sección A (Propósito del proyecto de guía sobre el registro y su relación con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*).

18. En cuanto a la sección B (Terminología e interpretación), se acordó lo siguiente: a) debía suprimirse el texto que figuraba entre corchetes en relación con los términos “modificación” y “cancelación” y debía examinarse en el comentario la cuestión de los múltiples acreedores garantizados; b) el término “modificación” debía referirse al hecho de agregar o cambiar información o de suprimir alguna información en una notificación del registro, pues la supresión de toda la información daría lugar a la cancelación, y los efectos jurídicos de una modificación debían examinarse en el comentario (véase el párr. 49 *infra*); c) debía aclararse en el comentario que, si bien una modificación podría dar lugar a que se suprimiera alguna información del fichero del registro accesible al público, esa información debía mantenerse en los archivos del registro; d) debía aclararse el término “cancelación” con una referencia a la recomendación 74 de la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*, según la cual, si bien la información consignada en una notificación podía retirarse del fichero del registro accesible al público a raíz de la cancelación o de la expiración de la vigencia de dicha notificación, esa información debía archivararse a fin de poder recuperarse, y los efectos legales de la cancelación debían examinarse en el

comentario (véase el párr. 49 *infra*); e) el término “notificación” debía usarse de forma sistemática en todo el proyecto de guía sobre el registro (véase el párr. 30 *infra*), y la expresión “notificación del registro” debía distinguirse de la expresión “notificaciones inscritas”; f) debía evitarse utilizar conjuntamente las expresiones “notificaciones inscritas” y “base de datos del registro”, que podían tener el mismo significado; g) el término “reglamento” debía explicarse con una referencia al proyecto de guía sobre el registro, sin perjuicio del derecho del Estado promulgante a decidir las cuestiones que debían incluirse en el reglamento o en la legislación sobre operaciones garantizadas; y h) la expresión “espacio previsto” debía incluirse en la terminología con el significado de lugar especial de la notificación designado por el registro para consignar cierta información especial. Con sujeción a esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección B.

19. En lo que respecta a la sección C (Objetivos clave y principios fundamentales), se acordó que debía acortarse a fin de evitar examinar cuestiones que se trataban en otras partes del proyecto de guía sobre el registro (por ejemplo, los objetivos clave de incrementar la certeza y la transparencia mediante un sistema de registro de notificaciones) o que no tenían que ver con el registro (por ejemplo, el enfoque funcional). Con sujeción a ese cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección C.

20. En lo que respecta a la sección D (Problemas de la transición), se acordó que: a) debía evitarse utilizar términos como “armonización”, que podrían implicar inadvertidamente que la nueva ley tal vez tendría que ser similar a la anterior; y b) por lógica, debía colocarse dicha sección después de la sección E (Información general sobre el régimen de las operaciones garantizadas y la función de la inscripción registral). Con sujeción a esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección D.

21. En lo que respecta a la sección E, se expresaron opiniones divergentes. Unos sugirieron que debía acortarse, si bien debía mantenerse en la Introducción del proyecto de guía sobre el registro para ofrecer orientación sobre conceptos y enfoques que podrían ser nuevos en muchos ordenamientos jurídicos. Otros opinaron que debía acortarse sustancialmente y centrarse más en los conceptos de la oponibilidad a terceros y la prelación y que las demás cuestiones debían pasar a examinarse en el anexo. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en examinar primero el contenido de la sección y volver después a la cuestión de dónde insertarla en el proyecto de guía sobre el registro (véase el párr. 27 *infra*).

22. En cuanto a la subsección E.2 (Concepto y función de la garantía real), se acordó que debía examinarse con atención todo ejemplo que se fuera a aportar de excepciones al enfoque de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* basado en la primacía del fondo sobre la forma. En cuanto a la subsección E.3 (Constitución de una garantía real), se acordó que el examen del producto debía limitarse a los puntos pertinentes que no se examinaran en otras partes del texto. En cuanto a la subsección E.4 (Oponibilidad a terceros de una garantía real), se convino en que el examen de la inscripción de las notificaciones en los registros de propiedad inmobiliaria debía ajustarse más a la recomendación 43 y al comentario correspondiente que figuraba en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

23. En cuanto a la subsección E.5 (Prelación de una garantía real), se acordó que: a) debía examinarse con atención la subsección E.5.a) a fin de asegurar su exactitud; b) en la subsección E.5.b) y en otras partes del proyecto de guía sobre el registro, el término “conocimiento” debía utilizarse en el sentido de “conocimiento de hecho” de conformidad con la Guía sobre las Operaciones Garantizadas; y c) la subsección E.5.d) debía revisarse para garantizar su exactitud y coherencia con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y la Guía sobre la Insolvencia.

24. En cuanto a la subsección E.6 (Amplitud de las inscribibles en el registro), se acordó que: a) el encabezamiento debía referirse al “alcance ampliado” de las inscribibles en el registro, dado que la amplitud de las inscribibles en el registro como resultado del enfoque funcional, integral y amplio de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se examinaba en otra parte del proyecto de guía sobre el registro; b) en cuanto a la cesión pura y simple, debía aclararse que no necesariamente eran aplicables las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* en materia de ejecución; y c) en cuanto a otras operaciones no garantizadas, había que ajustar más el examen a la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (en particular en lo referente al registro de medidas de ejecución y créditos privilegiados).

25. En cuanto a la subsección E.7 (Consideraciones relativas al conflicto de leyes), se acordó que debía aclararse que el carácter obligatorio de las reglas sobre el conflicto de leyes aplicables a los aspectos de las garantías reales relativos a la propiedad no afectaban a la autonomía de las partes en cuanto a la ley aplicable a los derechos y obligaciones de las partes. Con respecto a la subsección E.8 (Inscripción registral de la notificación), se acordó que se suprimiera el último párrafo puesto que se refería a cuestiones que ya se trataban en otras partes.

26. En cuanto a la subsección E.9 (Función de la inscripción registral y sus consecuencias jurídicas), se acordó que debía suprimirse el examen de la constitución, la oponibilidad a terceros y la prelación porque era repetitivo y que debía suprimirse o insertarse en otro lugar del texto el examen de la inscripción registral y la ejecución porque se refería a una cuestión diferente. Con respecto a las subsecciones E.10 y E.11, se acordó que debían acortarse y ajustarse más al examen pertinente que se hacía en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

27. Con sujeción a esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección E de la Introducción. En lo referente a la ubicación de la sección E en el texto, el Grupo de Trabajo acordó que debía mantenerse en la Introducción del proyecto de guía sobre el registro una versión más corta y más fácil de consultar.

C. Creación y funciones del registro de garantías reales (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1, párrs. 40 a 55)

28. En cuanto a la subsección A.1 (Creación del registro de garantías reales), se convino en que debía tratar únicamente de la creación del registro. Con respecto a la subsección A.4 (Otras consideraciones relativas a la creación del registro), se convino en lo siguiente: a) debía incluirse en ella el examen de las vías de acceso comunes y tal vez incluso el de la coordinación de registros; y b) en el contexto del examen de la capacidad de almacenamiento del fichero del registro, debía hacerse

referencia también a todo posible requisito relativo a la migración de datos de los registros existentes al registro de garantías reales.

29. Con respecto a la subsección A.5 (Condiciones de uso del registro), se convino en que podría mantenerse el examen de los servicios de inscripción adicionales con ejemplos de los servicios prestados a los usuarios de los sistemas de registro y al público, pero que esos ejemplos debían ser conformes con las recomendaciones de la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*.

30. Con respecto a la subsección A.6 (Registro electrónico o de documentos en papel), se convino en que habría que revisar el texto para asegurar que fuera claro, exhaustivo y preciso. A ese respecto, el Grupo de Trabajo reexaminó el término “notificación” y convino en que debía matizarse su significado en el proyecto de guía sobre el registro con una referencia a la comunicación por escrito (en papel o en formato electrónico) con respecto a una garantía real presentada para su inscripción registral. Se acordó también que debían simplificarse los dos párrafos sobre la inscripción y las búsquedas electrónicas directas (véase el párr. 18 *supra*).

31. En cuanto a la recomendación 3, se acordó lo siguiente: a) las remisiones a las recomendaciones pertinentes servían de orientación al lector y por tanto debían mantenerse; y b) debía incluirse una nueva recomendación en el proyecto de guía sobre el registro y hacerse una breve mención de ella en la recomendación 3, a fin de tener en cuenta, de conformidad con la recomendación 54, apartado f), de la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*, la obligación del registro de proteger la información del fichero mediante mecanismos de seguridad especialmente ideados para ello.

32. Con sujeción a los cambios antes mencionados (véanse los párrs. 28 a 31 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo I (Creación y funciones del registro de garantías reales).

D. Acceso a los servicios del registro (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1, párrafos 56 a 61 y A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrafos 1 a 10)

33. Con respecto a la subsección A.1 (Acceso del público) se acordó que: a) no era necesario repetir aquí el examen de las ventajas del acceso electrónico a los servicios de inscripción; y b) debían abordarse en otra parte del proyecto de guía sobre el registro las preocupaciones relacionadas con la privacidad del otorgante y del acreedor garantizado.

34. Con respecto a la subsección A.2 (Días y horas de funcionamiento del registro), se convino en que otro ejemplo de la consignación de la información contenida en las notificaciones en papel en el fichero del registro consistiría en que el personal del registro consignara dicha información en un plazo breve (por ejemplo, de unas horas) después de su presentación.

35. Con respecto a las subsecciones A.3 (Acceso a los servicios de inscripción y de consulta) y A.5 (Rechazo de una inscripción registral o de una consulta), se acordó lo siguiente: a) debían examinarse por separado el acceso a los servicios de inscripción y el acceso a los servicios de consulta; b) el examen del acceso a los servicios de inscripción debía ir seguido de un examen de los motivos de rechazo de la inscripción registral, y el del acceso a los servicios de consulta, de un examen

de los motivos de rechazo de la solicitud de consulta; c) el examen del rechazo de la solicitud de inscripción registral o de consulta debía reformularse para establecer la obligación del registro en los casos en que no se cumplieran las condiciones necesarias; y d) debía explicarse que, en el caso de la inscripción electrónica, el registro debía presentar los motivos de rechazo inmediatamente, mientras que en el caso de que la inscripción no fuera completamente electrónica, dichos motivos debían darse en el plazo más breve posible.

36. Con respecto a la subsección A.4 (No son necesarias la verificación de la identidad, las pruebas de autorización ni el examen del contenido de la notificación), se acordó lo siguiente: a) debía aclararse que no era necesario que el registro verificara la identidad del solicitante de la inscripción y, en cualquier caso, esa cuestión debía examinarse en la subsección A.3, relativa al acceso a los servicios de inscripción; b) también debían examinarse en ese contexto las medidas para proteger a los otorgantes frente a las inscripciones no autorizadas, con remisiones a otras secciones del proyecto de guía sobre el registro (por ejemplo, la sección sobre los casos de modificación y cancelación obligatorias de una notificación); y c) la cuestión de las modificaciones o cancelaciones no autorizadas por el acreedor garantizado debía examinarse en la sección sobre las copias de las notificaciones inscritas en el registro.

37. En cuanto a las recomendaciones 4 a 9, se acordó lo siguiente: a) por motivos de coherencia con la formulación de las recomendaciones de la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*, en la recomendación 5 las palabras “must be” debían reemplazarse por la palabra “is” en la versión inglesa (cambio que no se aplica al español); b) en la recomendación 5, apartado c) i), debía matizarse la alusión a la suspensión del acceso a los servicios de inscripción con una referencia a un plazo de tiempo razonablemente breve y al motivo de la suspensión (por ejemplo, la necesidad de mantenimiento); c) en las recomendaciones 6 y 7, las palabras tiene “derecho a inscribir una notificación” y tendrá “derecho a consultar” debían reemplazarse por palabras similares a las siguientes: “derecho a presentar una notificación para su inscripción” y “derecho a presentar una solicitud de consulta”, puesto que el registro podía rechazar una solicitud de inscripción o de consulta de conformidad con la recomendación 9; d) la recomendación 6 debía ir seguida de una recomendación relativa al rechazo de una solicitud de inscripción similar a la que figuraba en la recomendación 9, apartados a) y c), con la diferencia de que el rechazo debía ser obligatorio si no se cumplían las condiciones estipuladas; e) la recomendación 7 debía colocarse justo después de la recomendación 8; f) la recomendación 8 debía mantenerse con algunas mejoras en la redacción del apartado c); y g) el resto de la recomendación 9, relativo al rechazo de una solicitud de consulta, debía mantenerse con una formulación similar a la de los apartados b) y c), con la diferencia de que el rechazo debía ser obligatorio si no se cumplían las condiciones estipuladas.

38. En el contexto del examen de las recomendaciones 4 a 9 también se acordó que en el comentario se debía: a) distinguir claramente entre las cuestiones relacionadas con el acceso y las relativas a los motivos de rechazo de una solicitud de inscripción o de consulta; b) revisar el título del capítulo II para reflejar esa distinción; c) explicar la relación entre las recomendaciones 6 y 9 y la recomendación 54, apartado c), de la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*; y d) explicar que el registro podría exigir y mantener la identidad del

solicitante de la inscripción, pero no podría exigir la verificación de su identidad (más allá de la verificación mínima a que se hacía referencia en la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrafo 48).

39. Con sujeción a los cambios antes mencionados (véanse los párrafos 33 a 38 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo II (Acceso a los servicios del registro) del proyecto de guía sobre el registro.

E. Inscripción registral (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrafos 11 a 58)

40. Con respecto a la subsección A.1 (Fecha en que surte efecto la notificación inscrita en el registro), se acordó lo siguiente: a) el examen de la obligación del registro de asignar un número de inscripción a la notificación inicial debía tratarse como cuestión separada, puesto que no encajaba bajo el encabezamiento “Fecha en que surte efecto la notificación inscrita en el registro”; b) el examen de la prelación de las garantías reales a que se hiciera referencia en varias notificaciones inscritas exactamente al mismo tiempo podía suprimirse dado que no era pertinente en ese contexto, no se trataba de una situación probable y, en cualquier caso, quedaba suficientemente reflejado en las recomendaciones 70 y 76, apartado a), de la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*; c) debía hacerse hincapié en la importancia de cerciorarse del momento exacto en que la notificación inscrita surte efecto con una referencia a la apertura del procedimiento de insolvencia con respecto al otorgante, puesto que era más probable que esta se produjera al mismo tiempo que la inscripción; d) debía simplificarse y corregirse el examen del lapso transcurrido entre el momento en que el registro recibía la notificación y el momento en que esta pasaba a ser accesible a quienes consultaran el registro; e) debía explicarse claramente la obligación del registro de inscribir cada notificación en el fichero en el orden en que se recibiera (que era importante a efectos del orden de prelación de cada garantía real y no tenía por objeto solucionar el problema del lapso transcurrido) como cuestión separada de la obligación del registro de realizar dicha inscripción sin demora; y f) debía suprimirse el examen de las “fechas de validez”, puesto que no era pertinente en el contexto de un sistema de garantías reales en el que la fecha de entrada en vigor era el momento en que la notificación pasaba a ser accesible a quienes consultaran el fichero (y no el momento en que se recibía la notificación).

41. Con respecto a la subsección A.2 (Plazo de vigencia de la notificación inscrita en el registro), se acordó lo siguiente: a) el examen del requisito obligatorio de indicar en la notificación su plazo de vigencia debía insertarse en la parte del proyecto de guía sobre el registro relativa al contenido obligatorio de las notificaciones; y b) el examen de un plazo de vigencia por defecto en las opciones B y C debía suprimirse dado que no era conforme con la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*.

42. Con respecto a la subsección A.3 (Momento en que puede inscribirse una notificación), se convino en que debía acortarse el examen de la cuestión de la protección del otorgante frente a las inscripciones no autorizadas y debía incluirse una remisión en el proyecto de guía sobre el registro acerca de los casos obligatorios de modificación y cancelación de una notificación.

43. Con respecto a la subsección A.4 (Suficiencia de una notificación única) se acordó aclarar en el comentario que la inscripción de una notificación única era suficiente para lograr la oponibilidad a terceros de una o más garantías reales sobre el bien gravado descrito en la notificación y en favor del acreedor garantizado nombrado en la notificación.

44. Con respecto a la subsección A.5 (Indización u otra forma de organizar la información del fichero del registro), se acordó lo siguiente: a) el examen de la indización basada en el otorgante debía separarse del examen de la indización basada en los bienes; b) este último examen debía acortarse, como figuraba en el comentario de la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*, pero no se recomendaba; y c) se debía aclarar que la información en una notificación de modificación debía indizarse u organizarse de alguna otra manera de modo que, cuando se hiciera una consulta, se recuperara tanto la información consignada en la notificación inicial como la que figurara en todas las notificaciones de modificación relacionadas con esa notificación inicial.

45. Con respecto a la subsección A.6 (Integridad del fichero del registro) se convino en que: a) se debía examinar en el comentario la obligación del registro de proteger la información del fichero mediante mecanismos de seguridad fiables (véase párr. 31 *supra*); b) debía examinarse con mayor flexibilidad la función del personal del registro, pues podía variar de un Estado a otro, y en cualquier caso, debía autorizarse a dicho personal para dar asesoramiento práctico respecto del proceso de inscripción a los autores de inscripciones y, en particular, a los pequeños prestamistas; y c) debía trasladarse a la subsección A.7, relativa a la responsabilidad del registro, el examen de la prohibición de que el personal del registro proporcionara asesoramiento jurídico.

46. Con respecto a la subsección A.7 (Responsabilidad del registro) se acordó reformular su encabezamiento para no implicar que existiera responsabilidad del registro.

47. Con respecto a la subsección A.8 (Copia de la notificación inscrita en el registro) se acordó lo siguiente: a) se debía dividir la subsección en dos partes, una relativa a la obligación del registro de enviar copia de la notificación inscrita al solicitante de la inscripción y otra relativa a la obligación de este último de enviar copia al otorgante; b) se debía explicar en el comentario que el propósito de enviar copia de la notificación inscrita en el registro al otorgante era comprobar que se contaba con su autorización y que el alcance de la notificación se circunscribía a dicha autorización; y c) en el caso de la notificación inicial, debía enviarse la copia a la dirección del otorgante consignada en la notificación, mientras que en el caso de una notificación de modificación debía enviarse a esa dirección o a la dirección actual del otorgante conocida por el solicitante de la inscripción.

48. Con respecto a la subsección A.9 (Modificación de la información consignada en una notificación inscrita en el registro) se acordó lo siguiente: a) podía acortarse la subsección y trasladarse el examen de la modificación obligatoria a la parte correspondiente del proyecto de guía sobre el registro; y b) debía revisarse el encabezamiento para que dijera algo como “Modificación de una notificación inscrita en el registro”, dado que el término “modificación” ya incluía una referencia a la información consignada en una notificación.

49. A ese respecto, el Grupo de Trabajo volvió a examinar los términos “modificación” y “cancelación” en el proyecto de guía sobre el registro y acordó lo siguiente: a) la palabra “modificación” no debía referirse al hecho de suprimir información consignada en una notificación inscrita en el registro, pues en el caso de una modificación se añadiría información al fichero sin suprimir la información ya existente; y b) la palabra “cancelación” debía referirse al hecho de suprimir toda la información consignada en una notificación inscrita en el registro pero únicamente del fichero accesible al público, dado que esa información se mantendría archivada durante un largo período (véase asimismo el párr. 18 *supra*). No obstante, en vista de que esas palabras se utilizaban en distintos contextos en todo el proyecto de guía sobre el registro para hacer referencia a un nombre, un proceso o un efecto jurídico, se convino en revisar cuidadosamente el comentario para explicar el significado de dichas palabras según el contexto.

50. Con respecto a la subsección A.10 (Retiro de la información del fichero del registro accesible al público y archivo de esa información) se convino en que: a) podrían presentarse más ejemplos de situaciones en las que sería necesario recuperar información; b) no debía mencionarse la posibilidad de conservar en el fichero del registro accesible al público la información consignada en notificaciones que hubieran caducado o hubieran sido canceladas, puesto que ello no se ajustaba a las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*; y c) debía trasladarse el examen de la corrección de errores por el personal del registro a la subsección sobre la integridad del fichero del registro.

51. Con respecto a la subsección A.11 (Idioma de la notificación) se convino en lo siguiente: a) debía mencionarse la posibilidad de que el resultado de una consulta se expresara en un idioma oficial distinto al de la notificación inicial (concretamente, la posibilidad de que existieran múltiples idiomas oficiales); y b) no debía examinarse el uso de los números del documento de identidad personal como identificador del otorgante como forma de mitigar el problema del idioma puesto que, en cualquier caso, se tendría que facilitar el nombre del otorgante.

52. Con respecto a las recomendaciones 10 a 20, se acordó lo siguiente: a) la obligación del registro de asignar un número de inscripción a la notificación inicial debía tratarse en una recomendación separada puesto que no encajaba bajo el encabezamiento de la recomendación 10 (Momento en que surte efecto una notificación inscrita); b) en la recomendación 10 debía mantenerse la referencia a la “notificación inicial” (en lugar de la expresión “notificación inicial inscrita en el registro”) puesto que la notificación inicial recibiría un número de inscripción en el momento de su inscripción; c) el uso de las expresiones “notificación inscrita” e “inscripción registral” en la recomendación 11 y otras recomendaciones debía examinarse con cuidado y racionalizarse; d) debía revisarse la última parte de la recomendación 14, apartado b), de forma que dijera algo como “de modo que se pueda recuperar junto con la notificación inicial en su forma enmendada”, dado que la palabra “recuperar” transmitía más correctamente el significado de hallar información; e) debía revisarse la recomendación 16 para que hiciera referencia a la dirección consignada en la notificación, en el caso de las notificaciones iniciales, y a esa misma dirección o la dirección actual que conociera el solicitante de la inscripción en el caso de una notificación de modificación; y f) debía incluirse en la recomendación 19 una remisión a la recomendación 14 para asegurar que se

recuperara la información archivada junto con la notificación inicial en su forma enmendada.

53. Con sujeción a los cambios antes mencionados (véanse los párrs. 40 a 52 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo III (Inscripción registral) del proyecto de guía sobre el registro.

F. Información sobre la inscripción registral (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.3, párrafos 1 a 56)

54. Con respecto a la subsección A.1 (Información requerida en una notificación inicial) se acordó lo siguiente: a) debía examinarse la inclusión de toda la información requerida en la notificación como condición para que la notificación fuera aceptada (o no rechazada) por el registro, y no como condición para su eficacia; b) debía trasladarse el comentario relativo al identificador del otorgante a la parte del proyecto de guía sobre el registro en que abordaba ese mismo tema; c) debía revisarse el comentario de modo que dijera que en una consulta se revelaban las notificaciones inscritas contra el otorgante (en lugar de las garantías reales que pudieran haber sido otorgadas); d) debía examinarse detalladamente en el comentario la jerarquía entre los documentos utilizados para la identificación de los otorgantes que fueran personas físicas, de conformidad con el cuadro y la recomendación pertinentes; e) la correspondencia de los nombres consignados en la notificación inscrita en el registro con los nombres en otras bases de datos, que se efectuaba durante el proceso de inscripción, se aplicaba tanto a las personas físicas como a las jurídicas, por lo que debía examinarse en relación con ambas; f) debía examinarse la dirección del otorgante como información adicional que ni formaba parte del identificador del otorgante ni constituía un criterio de búsqueda, con las remisiones correspondientes a la parte del proyecto de guía sobre el registro en la que se trataba ese tema; g) debía examinarse en más detalle la cuestión del robo de identidad; h) debía racionalizarse el examen de los identificadores de los otorgantes que fueran empresas nacionales o extranjeras; i) debía revisarse el examen de los casos especiales para ajustarlo más al cuadro correspondiente; j) debía examinarse la cuestión de la dirección del otorgante sin alentar comunicaciones no solicitadas de terceros con los otorgantes; k) en el examen del contenido que debía tener una notificación debían incluirse remisiones al examen de la información incorrecta o insuficiente; l) debía explicarse en el comentario que el acreedor garantizado no podía proporcionar a terceros información sobre el otorgante sin su autorización.

55. Con respecto a la subsección A.2 (Información sobre el acreedor garantizado) se acordó que al fideicomisario o agente en una operación de préstamo sindicado se le considerara acreedor garantizado (y no representante del acreedor garantizado).

56. Con respecto a la subsección A.3 (Descripción de los bienes gravados) se acordó que: a) se debía explicar en el comentario que la descripción de un bien gravado podría ser específica o genérica, dependiendo de las características del bien y del patrimonio del otorgante; y b) no debía considerarse la descripción de los bienes con números de serie como un requisito, sino como una opción para permitir también la indización y búsqueda por números de serie, y había que aclarar que quien realizara la consulta no debía fiarse de unos resultados negativos tras una búsqueda por números de serie.

57. Con respecto a la subsección A.5 (Importe monetario máximo por el que puede ejecutarse una garantía real) se acordó que: a) debía aclararse en el comentario que el importe máximo mencionado en una notificación no debía usarse como oportunidad para imponer unos derechos de inscripción superiores a lo requerido para cubrir los gastos (recomendación 54, apartado i), de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*; y b) debía aclararse en el comentario que, aunque no hubiera reclamante concurrente, el acreedor garantizado podría ejecutar su garantía real hasta el importe máximo consignado en el acuerdo de garantía y la notificación, y reclamar el pago de todo saldo restante de la obligación garantizada únicamente como acreedor no garantizado.

58. Con respecto a la subsección A.6 (Información sobre el otorgante) se convino en que debía aclararse en el comentario que un error en los datos adicionales del otorgante (como su dirección, fecha de nacimiento o número de documento de identidad) no invalidaría la notificación inscrita a no ser que dificultara gravemente una consulta correcta del registro.

59. Con respecto a la subsección A.6.b) (Información sobre el acreedor garantizado), se convino en que: a) la modificación del identificador del acreedor garantizado tras la inscripción de la notificación no invalidaría la inscripción, y b) la cuestión de la modificación debía trasladarse a la parte del proyecto de guía sobre el registro relativa al examen de las modificaciones.

60. En cuanto a la subsección A.6.c) (Descripción de los bienes), se convino en que: a) la cuestión de la descripción de los bienes que tenían número de serie y la de considerar o no al número de serie un criterio de búsqueda debían examinarse por separado; b) cuando la indicación del número de serie fuese optativa, un error que se cometiese al consignar ese número no invalidaría la notificación inscrita, salvo que pudiera inducir gravemente a confusión al autor de una consulta correcta; c) cuando esa indicación fuese obligatoria, el error no invalidaría la notificación inscrita, a menos que la búsqueda efectuada en el archivo del registro por el número de serie correcto no permitiera encontrarla; d) debían examinarse las consecuencias que podía tener una declaración incorrecta hecha en la notificación inscrita acerca del período de vigencia de la inscripción, con objeto de aclarar, entre otras cosas, que: i) si en la notificación inscrita se indicaba un plazo más breve que el previsto, al expirar esta, su vigencia caducaría y podría restablecerse inscribiendo una nueva notificación, pero únicamente a partir de la fecha de esta última, y ii) si en la notificación inscrita se indicaba un plazo más prolongado que el previsto, los terceros no se verían perjudicados, ya que se les habría alertado de que podría existir una garantía real, y e) el examen de la cuestión del importe máximo y las consecuencias de los errores debía aclarar que: i) si el importe máximo indicado en la notificación fuese, por equivocación, menor que el importe máximo indicado en el acuerdo de garantía, el acreedor garantizado podría ejecutar su garantía real hasta el importe máximo y reclamar el saldo en calidad de acreedor no garantizado (con arreglo a otras leyes ajenas al régimen de las operaciones garantizadas), en caso de que hubiera otros acreedores concurrentes, y ii) si no hubiera otros acreedores concurrentes, el acreedor garantizado podría ejecutar su garantía real hasta el importe indicado en el acuerdo de garantía, ya que, sobre la base de ese acuerdo, la garantía real sería eficaz entre las partes.

61. Con respecto a las recomendaciones 21 a 27 (véase asimismo el párr. 77 *infra*) se convino en que: a) en la recomendación 22, apartado b), debía aclararse que cada

componente del nombre debía consignarse en el espacio que le estaba destinado; b) en las recomendaciones 26 y 27 debía revisarse la referencia a la notificación inicial o el aviso de modificación, ya que en la recomendación 21, apartado a), se aclaraba lo suficiente que las recomendaciones 21 a 27 eran aplicables a la notificación inicial, y la recomendación 28, apartado a) ii) y iii), adaptada de manera apropiada, podría aclarar que las recomendaciones aplicables a la incorporación de información en la notificación inicial también serían aplicables a la incorporación de información en el aviso de modificación, y c) la recomendación 27, apartado e), debía conservarse entre corchetes y debían hacerse los ajustes apropiados para impartir orientación sobre la manera de proteger a los terceros que actuaran basándose en una declaración incorrecta de la notificación inscrita acerca del período de vigencia o del importe máximo para poder ejecutar la garantía real.

62. A reserva de los cambios mencionados (véanse los párrs. 54 a 61 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo IV (Información sobre la inscripción registral) del proyecto de guía sobre el registro.

G. Información sobre la modificación o cancelación de una notificación (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párrs. 1 a 30)

63. Con respecto a la subsección A.1. a) (Observaciones generales), se convino en que: a) se debía ajustar la terminología para evitar que el texto se interpretara en el sentido de que una modificación podría traducirse en un cambio (a diferencia de la adición) en la información consignada en el registro; b) se debía esclarecer la cuestión de si una modificación requeriría la autorización del otorgante consignando para ello ejemplos (y no con un texto general de efecto económico adverso), tales como la agregación de bienes gravados o el aumento del importe máximo por el que se puede ejecutar una garantía real; c) se debían distinguir las situaciones en que el otorgante hubiera autorizado una modificación de las situaciones en que el otorgante no hubiera dado su autorización; d) se debía hacer hincapié en las modificaciones múltiples mediante una sola notificación; y e) el énfasis se debía poner en la orientación a los autores de las inscripciones, mientras que el texto en el que se imparte orientación al registro se debería trasladar al lugar apropiado del proyecto de guía sobre el registro.

64. Con respecto a la subsección A.1. b) (Modificación del identificador del otorgante), se convino en que: a) se hiciera referencia a números únicos permanentes (y no a números de la tarjeta de identidad) y al hecho de que su utilización como identificador suplementario no podría solucionar el problema resultante de la modificación del identificador del otorgante ya que el nombre seguiría siendo su principal identificador; b) era función del registro conservar el antiguo identificador del otorgante incluso en caso de que se consignara un nuevo identificador; c) se debía explicar el efecto que el antiguo y el nuevo identificador del otorgante tendrían en la oponibilidad a terceros y la prelación de la garantía real con la que se relacionaba la notificación; y d) se debería puntualizar la cuestión de si sería posible una consulta a partir tanto del nuevo identificador como del antiguo y, en tal caso, cuáles serían las consecuencias para terceros que se basaran en una consulta con resultado negativo.

65. Con respecto a la subsección A.1.c) (Transferencia de un bien gravado), se convino en que: a) se debían examinar en forma más racionalizada los diferentes enfoques adoptados por los Estados con respecto a la validez de la inscripción registral al producirse la transmisión del bien gravado; b) incluso en los Estados que no exigían una notificación de modificación, el solicitante de la inscripción podría efectuar dicha modificación si así lo deseara; y c) una modificación no entrañaba la supresión de información del fichero del registro.

66. Con respecto a la subsección A.1.e) (Asignación garantizada y transmisión de la garantía real), se convino en que: a) se debía hacer referencia al artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional; b) el nuevo acreedor garantizado no tendría que suministrar al registro prueba del consentimiento del acreedor garantizado original para inscribir una notificación de modificación, y la cuestión quedaría a discreción de las partes en su acuerdo; c) el registro no necesitaría revelar el hecho de que una notificación de modificación hubiese sido inscrita por el acreedor garantizado original o por el nuevo acreedor garantizado; y d) el acreedor garantizado no tiene ninguna obligación de revelar la identidad del cesionario por solicitud del otorgante.

67. Con respecto a las subsecciones A.1.f) (Adición de nuevos bienes gravados) y g) (Supresión de bienes gravados), se convino en que el examen de los casos en que el otorgante hubiese cumplido parcialmente la obligación garantizada se debía fusionar con el examen de la supresión de bienes gravados.

68. Con respecto a la subsección A.1.h) (Cambio de descripción de los bienes gravados) se convino en que: a) cuando la descripción de los bienes gravados incluida en la notificación inscrita fuera correcta pero ya no coincidiera con la descripción real de esos bienes debido a cambios en las características de estos, la inscripción seguiría siendo oponible a terceros siempre y cuando permitiera identificar razonablemente los bienes; b) cuando la descripción de los bienes gravados incluida en la notificación inscrita fuera errónea y en la notificación de modificación se corrigieran los errores, se lograría la oponibilidad a terceros a partir del momento en que se inscribiera la notificación de modificación.

69. Con respecto a la subsección A.1.i) (Prórroga del plazo de vigencia de la inscripción) se convino en que: a) la inscripción de una notificación de modificación para prorrogar ese plazo no debía ser una obligación, sino una opción, para el solicitante de la inscripción; b) la prórroga del plazo de vigencia antes de su caducidad era una modificación y no una nueva inscripción; c) había que incluir remisiones a la parte pertinente del proyecto de guía sobre el registro en la que se examinaban las opciones en relación con el plazo de vigencia; y d) no debía mencionarse la posibilidad de no fijar límite al plazo de vigencia, puesto que no era una medida recomendada en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

70. Con respecto a la subsección A.1.j) (Modificación global) se convino en acortar el examen y explicar cómo se efectuaba una modificación global con una única notificación.

71. Con respecto a la subsección A.2 (Cancelación voluntaria) se acordó que: a) el solicitante de la inscripción debía estar facultado para cancelar la notificación en cualquier momento; b) con el fin de facilitar la cancelación de notificaciones inscritas, no sería necesario disponer del identificador del otorgante para una notificación de cancelación; y c) debían examinarse todas las cuestiones

relacionadas con la presentación de una notificación de cancelación por uno de los acreedores garantizados en la notificación inscrita, entre ellas: i) el tipo de efecto que tendría esa notificación en los derechos de los demás acreedores garantizados y en terceros que confiaran en que esa información no existiera en el fichero del registro accesible al público; ii) si se necesitaría autorización de los demás acreedores garantizados y, de ser así, el mecanismo por el cual se obtendría dicha autorización; iii) si el registro debía configurarse para rechazar ese tipo de notificación y solicitar que se presentara como notificación de modificación; y iv) si el registro debía configurarse para tratar ese tipo de notificación como notificación de modificación.

72. Con respecto a la subsección A.3 (Corrección de caducidad o cancelación errónea) se acordó que debía explicarse lo siguiente en el comentario: a) independientemente de si la caducidad o cancelación de la notificación inscrita fuese errónea o no, se requeriría una nueva notificación inicial para corregir la caducidad o cancelación y restablecer la oponibilidad a terceros; y b) se podría examinar la cuestión conjuntamente con la cancelación voluntaria bajo un encabezamiento revisado (“Efecto de la caducidad o cancelación”).

73. Con respecto a las recomendaciones 28 a 31, se acordó que: a) al final de la recomendación 28, apartados a) ii) y iii), se debían añadir las palabras “en una notificación inicial”; b) en la recomendación 28, apartado b), debían suprimirse los corchetes y en el comentario se debía explicar que para los Estados que exigieran la revelación del identificador de una transmisión en una notificación de modificación, la recomendación debía reflejar un requisito, y en otros Estados, debía indicar una opción; c) en la recomendación 28, apartado d) solo debía conservarse la opción B y en el comentario debían abordarse ambas opciones para explicar mejor la opción recomendada; d) debía revisarse la recomendación 29 para ofrecer dos opciones diferentes; e) al final de la recomendación 30, se debían añadir las palabras “de la notificación inscrita a que se refiera la cancelación” y debía ajustarse la formulación de la recomendación a la formulación de otras recomendaciones; f) con respecto a la recomendación 31, apartado a) iii), debía explicarse en el comentario mediante ejemplos la diferencia entre los términos “inexacta” e “incorrecta”; g) en la recomendación 31, apartado c) se debían revisar las palabras “según proceda”, y tal vez reemplazarlas por palabras como “según los casos”; y h) el texto de la recomendación 31, apartado g) debía quedar sin corchetes.

74. Con sujeción a las modificaciones mencionadas (véanse párrs. 63 a 73 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo V (Información de modificación y cancelación) del proyecto de guía sobre el registro.

H. Consultas (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párrs. 31 a 41)

75. Con respecto a la subsección A.1 (Criterios para efectuar la consulta), se convino en que: a) debía suprimirse el comentario sobre el acceso a los servicios de consulta y sobre los resultados de la consulta ya que esas cuestiones se abordaban en otras partes del proyecto de guía sobre el registro; y b) en el comentario debía examinarse la cuestión del empleo del número de serie como criterio de consulta optativo.

76. Con respecto a la subsección A.2 (Resultado de la consulta) se convino en que: a) el examen debía racionalizarse e ilustrar detenidamente sistemas de inscripción registral que revelaran “correspondencias aproximadas”; b) se aclarara la diferencia entre los términos “correspondencia” y “correspondencia exacta”; y c) se explicaran las razones por las cuales no se necesitaba ninguna referencia a las fechas de validez.

77. Con respecto a las recomendaciones 32 y 33, se acordó que a) solo el nombre del otorgante debía ser un criterio de consulta y, en consecuencia, la referencia a información adicional sobre el otorgante en las recomendaciones 22, 23 y 24 podía trasladarse a la recomendación 21, apartado a) i) (véase también el párrafo 61 *supra*); y b) en la recomendación 33, apartado b), debía hacerse referencia explícitamente a correspondencias aproximadas si un Estado decidiese introducir cualquier excepción a la regla de la “correspondencia exacta”.

78. Con sujeción a las modificaciones mencionadas (véanse párrs. 75 a 77 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo VI (Consultas) del proyecto de guía sobre el registro.

I. Derechos de inscripción y de consulta (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párrs. 42 a 48)

79. Tras haber deliberado, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del capítulo VII (Derechos de inscripción y de consulta) sin modificaciones.

J. Ejemplos de formularios de registro (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.6)

80. Seguidamente el Grupo de Trabajo examinó ejemplos de formularios de registro y acordó que sería necesario introducir algunos cambios para reflejar las decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo en el presente período de sesiones y asegurar la coherencia interna de los ejemplos de formularios de registro. También se acordó que en el comentario se debía destacar la importancia para el comercio internacional de la coordinación entre los Estados con objeto de asegurar la armonización de las leyes y los reglamentos sobre las operaciones garantizadas, así como la normalización de los formularios de registro.

V. Labor futura

81. El Grupo de Trabajo señaló que había previsto celebrar su 23º periodo de sesiones en Nueva York, del 8 al 12 de abril de 2013.

B. Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 22º período de sesiones

(A/CN.9/WG.VI/WP.52 y Add.1 a Add.6)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
Prefacio	
Introducción	1-47
A. Propósito del proyecto de guía sobre el registro y su relación con la <i>Guía sobre las Operaciones Garantizadas</i>	1-8
B. Terminología e interpretación	9-16
C. Objetivos clave y principios fundamentales de un registro eficiente	17-18
D. Problemas de la transición	19-25
E. Información general sobre el régimen de las operaciones garantizadas y la función de la inscripción registral	26-47
1. Observaciones generales	26
2. Concepto y función de la garantía real	27-29
3. Constitución de una garantía real	30-34
4. Oponibilidad a terceros de una garantía real	35-40
5. Prelación de una garantía real	41-47

Prefacio

En su 42º período de sesiones (Viena, 29 de junio a 17 de julio de 2009), la Comisión tomó nota con interés de los temas de trabajo futuros examinados por el Grupo de Trabajo VI en sus períodos de sesiones 14º y 15º (A/CN.9/667, párr. 141, y A/CN.9/670, párrs. 123 a 126). En ese período de sesiones, la Comisión acordó que la Secretaría organizara un coloquio internacional a principios de 2010 para recabar las opiniones y el asesoramiento de expertos acerca de la posible labor futura en materia de garantías reales¹. De conformidad con esa decisión², la Secretaría organizó un coloquio internacional sobre las operaciones garantizadas (Viena, 1 a 3 de marzo de 2010). En el coloquio se examinaron varios temas, incluida la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles, las garantías reales sobre valores bursátiles que no estén en poder de intermediarios, una ley modelo sobre las operaciones garantizadas, una guía contractual para las

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párrs. 313 a 320.*

² *Ibid.*

operaciones garantizadas, la concesión de licencias de propiedad intelectual y la puesta en práctica de los textos de la CNUDMI sobre garantías reales. Participaron en el coloquio expertos procedentes de los países, de organizaciones internacionales y del sector privado³.

En su 43º período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010), la Comisión examinó una nota de la Secretaría sobre la posible labor futura en materia de garantías reales (A/CN.9/702 y Add.1). En la nota se abordaban todos los temas examinados en el coloquio. La Comisión reconoció que todos los temas presentaban interés y debían mantenerse en su futuro programa de trabajo para su examen en un futuro período de sesiones sobre la base de las notas que pudiera preparar la Secretaría, dentro de los límites de los recursos disponibles. No obstante, habida cuenta de los limitados recursos de que disponía, la Comisión acordó que debía concederse prioridad a la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles⁴.

Prevaleció el parecer, a dicho respecto, de que un texto relativo a la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles sería un complemento valioso de la labor ya realizada por la Comisión en materia de operaciones garantizadas y ofrecería a los Estados la orientación que tan urgentemente requieren para la apertura y el buen funcionamiento de un registro eficiente de las garantías reales. Se afirmó que la reforma del régimen de las operaciones garantizadas no podía llevarse a cabo eficazmente sin haber previamente abierto al público un registro eficiente de las garantías reales. También se puso de relieve que en la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (*“Guía sobre las Operaciones Garantizadas”*) no se abordaban con suficiente detalle las diversas cuestiones jurídicas, administrativas, de infraestructura y funcionales que era preciso resolver para asegurar el buen funcionamiento de un registro eficiente⁵.

La Comisión convino también en que, si bien podía confiarse al Grupo de Trabajo la decisión sobre la forma y la estructura específicas del texto, ese texto podría: a) incluir principios, directrices, un comentario, recomendaciones o un reglamento modelo; y b) basarse en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, en los textos preparados por otras organizaciones y en los regímenes nacionales que habían establecido registros de las garantías reales similares al registro recomendado por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Tras deliberar, la Comisión decidió encomendar al Grupo de Trabajo la preparación de un texto relativo a la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles⁶.

En su 18º período de sesiones (Viena 5 a 10 de noviembre de 2010), el Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles” (A/CN.9/WG.VI/WP.44 y Add.1 y Add.2). El Grupo de Trabajo comenzó mostrándose favorable a la preparación de un texto relativo a la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles,

³ Véanse los documentos del coloquio en www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/3rdint.html.

⁴ *Ibid.*, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17 y Corr.1), párrs. 264 y 273.

⁵ *Ibid.*, párr. 265.

⁶ *Ibid.*, párrs. 266 y 267.

observando que la práctica financiera había demostrado claramente que la eficacia de un régimen de las operaciones garantizadas dependía de que se dispusiera de un sistema de inscripción registral eficiente (véase A/CN.9/714, párr. 12). En cuanto a la forma y la estructura del texto que había de prepararse, el Grupo de Trabajo partió del supuesto de que se prepararía una guía acerca de la creación y el funcionamiento eficiente de un registro de las garantías reales sobre bienes muebles, en la que se incluirían principios, directrices, comentarios y tal vez un reglamento modelo. El Grupo de Trabajo convino también en que el texto que se propusiera para dicha guía fuera compatible con el régimen legal de las operaciones garantizadas recomendado por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, sin dejar, por ello, de tener en cuenta la diversidad de los enfoques adoptados en los reglamentos por los que se regían los registros más modernos tanto nacionales como internacionales. Se observó además que, con arreglo a lo recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (recomendación 54, apartado j)), la guía que se propusiera para los futuros registros debería tener en cuenta la necesidad de facilitar la inscripción de notificaciones consignadas sobre soportes tanto electrónicos como de papel, a fin de que las partes interesadas pudieran inscribir su notificación o hacer su consulta por vía electrónica o sobre papel (A/CN.9/714, párr. 13). Se pidió a la Secretaría que preparara un proyecto de texto para la guía registral propuesta a la luz de las deliberaciones y de las conclusiones a que llegara el Grupo de Trabajo (A/CN.9/714, párr. 11).

En su 19º período de sesiones (Nueva York, 11 a 15 de abril de 2011), el Grupo de Trabajo examinó las notas preparadas por la Secretaría, tituladas “Proyecto de guía para un registro de las garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.46 y Add.1 y Add.2) y “Proyecto de reglamento modelo” (A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.3). El Grupo de Trabajo examinó en primer lugar la forma y el contenido del texto que habría de prepararse. A juicio de una delegación, habría que elaborar una guía autónoma en la que figurara una parte pedagógica que presentara el régimen de las operaciones garantizadas que se recomendaba en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, así como una parte práctica, que consistiría en un reglamento modelo para la inscripción de garantías y un comentario al respecto (véase A/CN.9/719, párr. 13). Otra delegación consideró que debía hacerse hincapié en un reglamento modelo para la inscripción de garantías y el comentario al respecto, que serviría de guía práctica para los Estados que hubieran promulgado el régimen de las operaciones garantizadas recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* con respecto a las cuestiones que habría que abordar a la hora de establecer y administrar un registro general de las garantías reales (véase A/CN.9/719, párr. 14). En ese período de sesiones se manifestaron también diversas opiniones acerca de si el texto debía presentarse como reglamento modelo o como recomendaciones (A/CN.9/719, párr. 46). El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada del texto que reflejara las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/714, párr. 12).

En su 44º período de sesiones (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011), la Comisión examinó los informes de los períodos de sesiones 18º y 19º del Grupo de Trabajo (A/CN.9/714 y A/CN.9/719, respectivamente). En ese período de sesiones, se destacó la importancia de la labor realizada por el Grupo de Trabajo VI, en particular teniendo en cuenta los esfuerzos realizados actualmente por varios Estados para establecer un registro general de las garantías reales y las importantes consecuencias beneficiosas que tendría el funcionamiento de un registro de este tipo

en la oferta y el costo del crédito. En cuanto a la forma y el contenido del texto que habría de prepararse, se indicó que, optando por el enfoque seguido en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, el texto debía presentarse en forma de guía con un comentario y recomendaciones, y no como un texto con un reglamento modelo y un comentario al mismo. A este respecto, se observó que la siguiente versión del texto sometido al Grupo de Trabajo se presentaría de forma tal que se dejara abierta la cuestión hasta que el Grupo de Trabajo formulara una decisión. Tras un debate, la Comisión convino en que no era preciso modificar el mandato del Grupo de Trabajo, que confiaba a este la decisión sobre la forma y el contenido del texto que había de prepararse, y que, en todo caso, la Comisión adoptaría la decisión final una vez que el Grupo de Trabajo hubiera concluido su labor y hubiera presentado el texto a la Comisión⁷.

En su 20º período de sesiones (Viena, 12 a 16 de diciembre de 2011), el Grupo de Trabajo prosiguió su labor basándose en una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía para un registro de las garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.48 y Add.1 a Add.3). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo convino en que el texto debía adoptar la forma de una guía (“proyecto de guía sobre el registro”) con un comentario y recomendaciones similares a los de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Además, el Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en que, cuando en el proyecto de guía sobre el registro se propusieran opciones, se incluyeran ejemplos de reglas modelo en un anexo de dicho proyecto (A/CN.9/740, párr. 18). En cuanto a la presentación del texto, se acordó que el proyecto de guía sobre el registro se presentara como texto aparte, independiente y amplio, que estuviera en consonancia con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y que se titulara provisionalmente “Guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de las garantías reales” (A/CN.9/740, párr. 30).

En su 21º período de sesiones (Nueva York, 14 a 18 de mayo de 2012), el Grupo de Trabajo examinó una nota de la secretaria titulada “Proyecto de guía legislativa técnica relativa a la aplicación de la Guía para un registro de las garantías reales. Anexo I. Terminología y recomendaciones” (A/CN.9/WG.VI/WP.50 y Add.1 y Add.2). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección relativa a la terminología y de las recomendaciones del proyecto de guía sobre el registro (A/CN.9/743, párr. 21). Además, el Grupo de Trabajo acordó que el proyecto de guía se concluyera y se sometiera a la aprobación de la Comisión en su 46º período de sesiones, previsto para 2013 (A/CN.9/743, párr. 73).

En su 45º período de sesiones (Nueva York, 25 de junio a 6 de julio de 2012), la Comisión examinó los informes de los períodos 20º y 21º del Grupo de Trabajo (A/CN.9/740 y A/CN.9/743, respectivamente). En ese período de sesiones la Comisión expresó su gratitud al Grupo de Trabajo y le pidió que agilizará y concluyera su labor, de modo que el proyecto de guía se le pudiera presentar para darle su aprobación final y adoptarlo en su 46º período de sesiones, que se celebraría en 2013⁸.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que el prefacio será actualizado después de cada sesión del Grupo de

⁷ *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 233.

⁸ *Ibid.*, Sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 99.

Trabajo y quedará terminado después que la Comisión apruebe el proyecto de guía sobre el registro, en su 45º periodo de sesiones, en 2013.]

Introducción

A. Propósito del proyecto de guía sobre el registro y su relación con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*

1. La *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas* (“*Guía sobre las Operaciones Garantizadas*”) trata de toda la gama de cuestiones que deberían abordarse en un régimen moderno de operaciones garantizadas (complementada, con respecto a las garantías reales sobre la propiedad intelectual, por el *Suplemento relativo a las garantías reales sobre propiedad intelectual*; el “*Suplemento*”). La creación de un registro que permita informarse acerca de la posible existencia de una garantía real sobre bienes muebles constituye una característica fundamental del régimen que se recomienda en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y de las iniciativas favorables a una reforma general de la legislación en esta esfera. En el capítulo IV de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se hacen ya comentarios y recomendaciones sobre muchas cuestiones concernientes a la inscripción registral de las garantías reales. Además, en los capítulos III y V de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se tratan las cuestiones conexas de la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real.

2. Sin embargo, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no se examinan, al menos en detalle, la multitud de cuestiones jurídicas, tecnológicas, administrativas y funcionales que habrán de resolverse para el buen funcionamiento de un registro de las garantías reales. Ello está de acuerdo con el enfoque legislativo más común, según el cual las normas detalladas aplicables al establecimiento y funcionamiento del registro, así como al proceso de inscripción y búsqueda o consulta, se tratan en reglamentos, directrices ministeriales y demás. De este modo, el proyecto de guía legislativa técnica para la creación de un registro de las garantías reales (“proyecto de guía sobre el registro”) procura poner en práctica la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* abordando estas cuestiones en mayor detalle.

3. Conviene subrayar desde un principio que las recomendaciones del proyecto de guía sobre el registro se formulan para ser aplicadas por los Estados que han establecido un régimen de operaciones garantizadas que responde, básicamente, a las recomendaciones formuladas en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. De ello se desprende que, a fin de comprender el marco jurídico en que se propone que funcione el registro, todo usuario del proyecto de guía sobre el registro debería tener un conocimiento básico del régimen de operaciones garantizadas que se prevé en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Así, en la sección E de la Introducción al proyecto de guía sobre el registro se ofrece una descripción concisa del régimen de operaciones garantizadas recomendado por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. En otros capítulos del proyecto de guía sobre el registro se incluye orientación adicional sobre las cuestiones abordadas en el régimen de las operaciones garantizadas recomendado por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Con todo, si se quiere alcanzar una comprensión cabal del tema,

convendría leer el proyecto de guía sobre el registro junto con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

4. La experiencia de los Estados que han establecido ya el tipo de registro general de las garantías reales previsto en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* es una clara muestra de las grandes ventajas que la tecnología de la información aporta a la eficiencia de un registro de este tipo. En particular, en lo relativo a los aspectos técnicos de diseño y funcionamiento del registro, el proyecto de guía sobre el registro trata de sacar enseñanzas de dichos precedentes. Además, en el proyecto de guía sobre el registro se recurre a otras fuentes internacionales, entre las que cabe citar las siguientes:

a) Reforma legislativa y de política registral del Banco Asiático de Desarrollo: guía sobre los registros de bienes muebles (2002);

b) Publicidad de las garantías reales: Directrices relativas al establecimiento de un registro de gravámenes, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) (2004);

c) Publicidad de las garantías reales: Definición de normas del BERD para los registros de gravámenes (2005);

d) Principios, definiciones y reglamento modelo de un proyecto de marco común de un derecho privado europeo, vol. 6, libro IX (Garantías reales sobre bienes muebles), capítulo 3 (Oponibilidad a terceros), sección 3 (Inscripción), 2010, preparado por el Grupo de estudio sobre un código civil europeo y por el Grupo de investigaciones acerca del derecho privado de la CEE (Acquis Group);

e) Reglamento Modelo para el Registro en virtud de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias (2009) de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

f) Publicación de la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) sobre los Sistemas de Operaciones Garantizadas y los Registros de Gravámenes (2010); y

g) Convenio relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil (Ciudad del Cabo, 2001) y sus Protocolos, por los que se establecen registros internacionales (que, pese a estar basados en el bien gravado y admitir la inscripción de operaciones distintas de las operaciones garantizadas, funcionan mediante un sistema de inscripción de notificaciones que determina la oponibilidad a terceros y el orden de prelación de la garantía inscrita).

5. Las fuentes nacionales, regionales e internacionales que se acaban de citar están de acuerdo, en general, pero no siempre hasta el último detalle, con las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Siempre que ha sido procedente, en el proyecto de guía sobre el registro se explica la razón de ser del enfoque que se recomienda en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* en comparación con otros enfoques posibles.

6. El proyecto de guía sobre el registro está dirigido a todas las personas interesadas en dicho registro o que hayan de participar activamente en su diseño y puesta en marcha, o que puedan verse afectadas por su apertura o estar interesadas en su creación y funcionamiento, entre las que cabe citar:

- a) Los encargados de formular políticas para la aplicación de las recomendaciones contenidas en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, especialmente en relación con la creación de un registro de garantías reales;
- b) Los diseñadores de sistemas de registro, incluido el personal técnico encargado de preparar las especificaciones de diseño o de cumplir los requisitos del equipo y los programas informáticos del registro;
- c) Los administradores y el personal del registro;
- d) Los usuarios del registro, incluidos los posibles acreedores garantizados, las agencias de información sobre solvencia crediticia, otros acreedores del otorgante de una garantía real y el representante de la insolvencia del otorgante, así como todas las demás personas cuyos derechos podrían verse afectados por una garantía real, por ejemplo, el posible comprador de un bien gravado;
- e) La comunidad jurídica en general (jueces, árbitros y abogados en ejercicio); y
- f) Toda persona o entidad que haya de intervenir en la reforma del régimen de las operaciones garantizadas y en la prestación de asistencia técnica (tales como el Banco Mundial, el BERD, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo).

7. No todos los que hayan de leer el proyecto de guía estarán versados en las complejidades del régimen de las operaciones financieras garantizadas y es posible que algunos no tengan siquiera formación jurídica. Por ello, el proyecto de guía ha sido redactado en “lenguaje sencillo” y se vale de recursos didácticos para facilitar la comprensión.

8. En el proyecto de guía sobre el registro se utiliza una terminología jurídica genérica y neutral, compatible con la empleada en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Por consiguiente, puede adaptarse fácilmente a las diversas tradiciones jurídicas y los estilos de redacción propios de los distintos Estados. El proyecto de guía sobre el registro se ha formulado también con flexibilidad a fin de permitir su aplicación de conformidad con las convenciones de redacción locales en cuanto a los tipos de normas que han de incorporarse en las leyes principales y cuáles habrán de relegarse a los reglamentos o a directrices ministeriales o administrativas.

B. Terminología e interpretación

9. La sección sobre terminología e interpretación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la Introducción, secc. B, párr. 20) se aplica también al proyecto de guía sobre el registro. La terminología del proyecto de guía sobre el registro refleja igualmente el refinamiento de estas definiciones y las explicaciones de términos adicionales que se encuentran en los diversos capítulos de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

10. Por ejemplo, cuando en el proyecto de guía sobre el registro se usa la expresión “bien futuro”, significa, como se explica en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cualquier bien que empiece a existir o sea adquirido por el otorgante después del momento en que se concierta el acuerdo de garantía (véase

la Guía *sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párr. 8, cap. II, párr. 51, y cap. V, párr. 151).

11. Sin embargo, en el proyecto de guía sobre el registro se refinan ciertas disposiciones relativas a la terminología y la interpretación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, y también se introducen otros términos, según se indica a continuación:

a) Dirección

Por “dirección” se entenderá: i) una dirección física, con nombre y número de calle, ciudad, código postal y estado; ii) un número de apartado de correos, ciudad, código postal y estado; iii) una dirección electrónica; o iv) una dirección que equivalga a lo especificado en i), ii) o iii).

b) Modificación

Por “modificación” se entenderá el acto de agregar, suprimir o cambiar la información contenida en una notificación inscrita, [por el único y solo solicitante de la inscripción o, si hay más de un autor, algunos de ellos,] así como el efecto de ese acto.

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar el texto que figura entre corchetes en las definiciones de “modificación” y “cancelación”, que, según se explica en el párr. 12 infra, tiene por objeto distinguir entre una modificación y una cancelación en los casos en que hay más de un solicitante de la inscripción.]

12. Entre los ejemplos de modificaciones cabe citar los siguientes: a) la prórroga o reducción del período de vigencia de una notificación (de ser aplicable); b) la adición o supresión o modificación del identificador o la dirección de un acreedor garantizado o del otorgante; c) la adición o supresión de bienes gravados; y d) la modificación del importe monetario máximo por el que se pueda ejecutar la garantía real (de ser aplicable) (para un examen de estas modificaciones, véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrs. 47 a 50 y A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párrs. 1 a 22). Si hay varios autores de la inscripción y uno suprime información, eso constituye una modificación. Solo la supresión de toda la información por todos los autores de la inscripción constituye una cancelación (véase el término “cancelación” a continuación).

c) Por “cancelación” se entenderá el acto de suprimir toda la información contenida en una notificación inscrita [por el único y solo solicitante de la inscripción o, si hay más de un autor, por todos ellos].

d) Otorgante

Por “otorgante” se entenderá la persona identificada en la notificación como otorgante.

e) Ley

Por “ley” se entenderá la ley que rige las garantías reales sobre bienes muebles.

13. Por “ley que rige las garantías reales sobre bienes muebles” se entenderá toda ley basada en las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

Esto se debe a que las recomendaciones del proyecto de guía sobre el registro solo podrán ser aplicadas por los Estados que hayan promulgado o estén preparados para promulgar una ley sobre operaciones garantizadas que esté fundamentalmente de acuerdo con las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Por ejemplo, para poder aplicar las recomendaciones del proyecto de guía sobre el registro, un Estado tendría que haber promulgado o estar dispuesto a promulgar una ley sobre operaciones garantizadas que prevea la inscripción de notificaciones (más que de documentos) y trate la inscripción registral como método para hacer que una garantía real sea oponible a terceros (y no tanto para crear también una garantía real).

f) Notificación

Por “notificación” se entenderá toda comunicación escrita (consignada en papel o electrónica) que incluya una notificación inicial, una notificación de modificación o una notificación de cancelación.

14. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se emplea el término “notificación” (o “aviso”) con el sentido general de comunicación (es decir, en un sentido más amplio que en el proyecto de guía sobre el registro. Así pues en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se utilizan los términos “aviso” y “notificación” en el sentido de comunicación a fin de abarcar no solo un formulario (o ventana informática) que se utilice para transmitir información al registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, B, “notificación”, y recomendaciones 54, apartado b), y 57), sino también otras comunicaciones como las notificaciones conexas, que no se inscriben en el registro, que los acreedores garantizados deben enviar en el contexto de la ejecución de sus garantías reales (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 149 a 151). En el capítulo IV de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se complementa el significado del término “notificación” en el contexto de la inscripción registral refiriéndose a: a) “la información contenida en una notificación” o “el contenido de la notificación” (*Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 54, apartado d), y 57); y b) al “fichero del registro” con el sentido de la información contenida en todas las notificaciones que han sido aceptadas por el registro e ingresadas en la base de datos del registro y que puede consultar el público (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 70). En el proyecto de guía sobre el registro se emplea el término “notificación” solo en el sentido más estrecho, con mayor hincapié en la información contenida en la comunicación de papel o electrónica consignada en el registro que en el medio de la comunicación. Por consiguiente, el término “notificación”, tal como se emplea en el proyecto de guía sobre el registro, deberá tomarse en ese sentido.

g) Solicitante de la inscripción

Por “solicitante de la inscripción” se entenderá la persona identificada en la notificación como el acreedor garantizado.

15. El solicitante de la inscripción puede ser el acreedor garantizado o su representante (véase la recomendación 57, apartado a)).

h) Director del registro

Por “director del registro” se entenderá la persona nombrada con arreglo a la ley y el reglamento para que supervise y administre el funcionamiento del registro.

i) Inscripción

Por “inscripción” se entenderá la incorporación en la base de datos del registro de la información consignada en una notificación.

j) Número de inscripción

Por “número de inscripción” se entenderá el identificador alfanumérico único asignado a una notificación inicial inscrita en el registro y permanentemente asociado a esa notificación y toda notificación posterior conexas de modificación o cancelación.

k) Fichero del registro

Por “fichero del registro” se entenderá la información contenida en todas las notificaciones inscritas que se incorpora a la base de datos del registro e incluye tanto la información a disposición del público para su consulta como la información contenida en las notificaciones canceladas, que se conservan en los archivos.

16. La expresión “fichero del registro” incluye todas las notificaciones inscritas y no solamente las notificaciones relacionadas con un otorgante determinado. Por esta razón, para remitirse a una notificación concreta contenida en el fichero del registro, se hace referencia a una “notificación inscrita”.

l) Reglamento

Por “reglamento” se entenderá el conjunto de reglas que ponen en práctica las disposiciones de la ley relativa al registro.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si, en caso de que la legislación sobre operaciones garantizadas consista en dos o más leyes (por ejemplo, una dedicada a todas las normas de fondo, otra sobre las reglas de conflictos de leyes y otra de creación del registro), las reglas relacionadas con la inscripción registral se recogerán en disposiciones subordinadas (por ejemplo, un reglamento aprobado de manera independiente) con respecto a todas estas leyes. En tal caso, el alcance del término “reglamento” podrá ampliarse ligeramente, más allá de los límites de un texto por el que se establece el registro, y explicarse en el comentario. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar también si, dada su importancia, ha de explicarse la expresión “espacio previsto”, más o menos de la manera siguiente: por “'espacio previsto' se entenderá el lugar especial de la notificación designado por el registro para consignar cierta información especial”.]

C. Objetivos clave y principios fundamentales de un registro eficiente

17. Los objetivos clave y los principios fundamentales de todo régimen eficaz y eficiente de las operaciones garantizadas se examinan en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la Introducción, sección D) y son pertinentes para la creación y el funcionamiento de un registro de garantías reales eficiente. De especial pertinencia son los que se mencionan a continuación: a) el objetivo clave de incrementar la certeza y la transparencia al prescribir la inscripción de las notificaciones en un registro general de las garantías reales (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, párr. 54 y recomendación 1, apartado f));

y b) la política fundamental de adoptar un enfoque funcional, integrado y amplio de las operaciones garantizadas y establecer un registro general de las garantías reales (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, párrs. 62 y 66).

18. En consonancia con los objetivos clave y las políticas fundamentales de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, el proyecto de guía sobre el registro se basa en los siguientes principios generales:

a) Eficiencia jurídica: las directrices jurídicas y funcionales que han de regir todos los servicios del registro, incluidas la inscripción y las consultas, deberían ser sencillas, claras y precisas;

b) Eficiencia funcional: los servicios del registro, incluidos los de inscripción y consulta, deberían estar diseñados con miras a que sean tan rápidos y económicos como sea posible, velando al mismo tiempo por la seguridad y accesibilidad de la información incorporada en el fichero del registro; y

c) Igualdad de trato para todos los usuarios del registro: el marco jurídico y funcional del registro debería estar diseñado para lograr el justo equilibrio entre todas las personas que puedan tener interés en el alcance y contenido de la información incorporada en el registro de las garantías reales, y la disponibilidad de esa información, incluidos los posibles otorgantes y acreedores garantizados, los demás acreedores del otorgante y su representante de la insolvencia, y otros reclamantes concurrentes posibles, tales como compradores potenciales de los bienes gravados por una garantía real.

D. Problemas de la transición

19. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* contiene un examen detenido de las diversas cuestiones que los Estados que piensan aplicar sus recomendaciones pueden desear tener en cuenta (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, sección E). Entre estas cuestiones cabe mencionar la armonización con las leyes vigentes, los métodos legislativos y las técnicas de redacción, así como las cuestiones relacionadas con la asimilación después de la promulgación.

20. La armonización con el derecho vigente es importante puesto que una ley basada en las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* puede muy bien constituir una desviación considerable de la legislación anterior. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* contiene un conjunto de recomendaciones equilibradas y eficientes que rigen la transición de la legislación vigente a la nueva legislación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 228 a 234). En particular, en estas recomendaciones se abordan dos importantes problemas de la transición: la fecha en que habrá de entrar en vigor la nueva ley (la “fecha de entrada en vigor”) y el grado en que ese nuevo régimen será aplicable a las operaciones o las garantías reales existentes antes de esa fecha.

21. En general, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el régimen de las operaciones garantizadas que se prevé en ella sea aplicable a todas las garantías reales, incluidas las ya existentes en la fecha de entrada en vigor. Sin embargo, reconoce cuatro importantes excepciones. En primer lugar, la ley vigente se aplica a las cuestiones que estén siendo dirimidas en el marco de un litigio o de otro procedimiento vinculante de solución de controversias iniciado

antes de la fecha de entrada en vigor (sin embargo, si la ejecución extrajudicial de una garantía real ha comenzado antes de la fecha de entrada en vigor, podrá continuar en virtud de la nueva ley; véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 229). En segundo lugar, la normativa legal anterior determinará si se constituyó una garantía real antes de la fecha de entrada en vigor (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 230). En tercer lugar, una garantía real que haya pasado a ser oponible a terceros conforme a la normativa legal anterior conservará su eficacia frente a terceros hasta uno de los siguientes momentos, según cuál se dé primero: a) el momento en que deje de ser oponible en virtud de la normativa legal anterior; y b) hasta la expiración de un plazo especificado en la ley después de la fecha de entrada en vigor (el “período de transición”) (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 231). Según este criterio, el titular de una garantía real creada con arreglo al régimen anterior recibe un plazo de transición para cumplir con los requisitos de oponibilidad a terceros con arreglo al nuevo régimen de operaciones garantizadas. Y, en cuarto lugar, la prelación de una garantía real será determinada por la normativa legal anterior cuando: a) la garantía real y los derechos de todos los reclamantes concurrentes hubieran nacido antes de la fecha de entrada en vigor; y b) no se haya producido ningún cambio en la prelación de esos derechos desde la fecha de entrada en vigor (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 233).

22. El nuevo registro general de las garantías reales previsto en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* daría a todos los acreedores garantizados existentes una forma rápida, expedita y barata de mantener la oponibilidad contra terceros y la prelación de sus garantías reales. Además, el nuevo registro permitiría a los otorgantes utilizar con más facilidad que conforme a los regímenes anteriores el valor pleno de sus bienes como garantía de crédito, porque podrían crear garantías reales sobre los mismos bienes en favor de más de un acreedor garantizado siempre que quedara clara la prelación de cada uno de ellos.

23. Si en el Estado promulgante ya existe un registro de las garantías reales sobre bienes muebles, deberán abordarse otros problemas de la transición. Por ejemplo, si se proyecta que el nuevo registro abarque las garantías reales que antes estaban comprendidas en el ámbito de un registro existente, el Estado promulgante o la entidad privada encargada de poner en marcha el registro podría asumir la responsabilidad de transmitir la información consignada en los ficheros existentes al nuevo fichero del registro. Sin embargo, como ya se dijo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la carga de la transferencia corra por cuenta de los acreedores garantizados, ofreciéndoseles un plazo de transición (por ejemplo, un año) para hacer una inscripción o conseguir por otros medios que la garantía real sea oponible a terceros. Este último enfoque se ha utilizado con considerable éxito en varios Estados (especialmente cuando ese nuevo registro es gratuito). Si se opta por esta variante, debería proporcionarse un espacio o recuadro en el formulario de inscripción para aclarar que la inscripción constituye la continuación (o transmisión) de otra efectuada antes de la entrada en funcionamiento del nuevo registro (para un examen más detenido de estos tipos de problemas de transición, véase el capítulo XI de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*).

24. Los Estados que estén considerando la posibilidad de llevar a la práctica el proyecto de guía sobre el registro también tendrán que tener en cuenta las cuestiones relacionadas con los métodos legislativos y las técnicas de redacción. Algunas de las recomendaciones del proyecto de guía sobre el registro reiteran o aplican las recomendaciones formuladas en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* debido a su importancia o su pertinencia para la administración del registro o su diseño técnico. Entre esas recomendaciones cabe citar las siguientes: 8 (véanse las recomendaciones 55, apartado b), y 54, apartado d)); 10, apartado a) (véase la recomendación 70); 11 (véase la recomendación 69); 12 (véase la recomendación 67); 13 (véase la recomendación 68); 16 (véase la recomendación 55, apartado c), y d)); 21 (véase la recomendación 57); 26, apartado a) (véase la recomendación 63); 27, apartado a) (véase la recomendación 58); 27, apartado b) (véase la recomendación 64); 27, apartado c) (véase la recomendación 65); 31 (véase la recomendación 72). Las recomendaciones restantes se refieren a cuestiones de inscripción netamente técnicas. Los Estados promulgantes deberán considerar si han de ocuparse de todas estas cuestiones en la legislación sobre las operaciones garantizadas, en el reglamento del registro, en las condiciones de uso del registro o en todos estos textos o en más de uno de ellos.

25. Los Estados promulgantes también deberán considerar los problemas de la asimilación posterior a la promulgación del nuevo régimen y, en particular, la necesidad de establecer un programa encaminado a familiarizar a los posibles usuarios del registro con su funcionamiento. Más concretamente, a fin de asegurarse de que el registro se establezca sin tropiezos y sus servicios sean utilizados por los usuarios, los Estados promulgantes deberán considerar la posibilidad de confiar a un equipo encargado de la puesta en marcha la tarea de formular programas de educación y concienciación, difundiendo el material de promoción y explicativo y organizando sesiones de capacitación. El equipo encargado de la puesta en marcha debería elaborar también instrucciones sobre la forma de consignar la información en los formularios impresos de inscripción y en las pantallas electrónicas.

E. Información general sobre el régimen de las operaciones garantizadas y la función de la inscripción registral

1. Observaciones generales

26. Como ya se dijo, un registro general de las garantías reales no existe en el vacío. Es parte integrante del régimen de operaciones garantizadas recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. En consecuencia, en este capítulo se ofrece información general sobre ese régimen, prestando especial atención a la función jurídica y a las consecuencias de la inscripción registral. Para una información más detallada, se recomienda al lector que consulte la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

2. Concepto y función de la garantía real

27. Con arreglo a la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, la garantía real es un derecho real (*ius in rem*, es decir, un derecho que, al igual que la propiedad, está constituido sobre la propia cosa y que es, por eso mismo, distinto de los derechos personales) que se confiere a un acreedor, mediante contrato, en garantía del pago

de un préstamo o del cumplimiento de otra obligación (véanse las expresiones “garantía real” y “otorgante” en la Introducción a la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, sección B). La función de la garantía real es reducir el riesgo de pérdida que pueda suponer para un acreedor garantizado el impago de su deuda garantizada, facultándole para hacer valer su derecho a percibir, a título de fuente supletoria de reembolso, el valor realizable de los bienes gravados, con prelación sobre los derechos de los demás acreedores del otorgante. Por ejemplo, si una empresa toma fondos prestados contra la garantía de su equipo industrial e incumple su obligación de reembolsar el préstamo, un acreedor garantizado con una garantía real sobre ese equipo estará facultado para obtener posesión del equipo, enajenarlo y destinar el producto de la venta al pago del saldo pendiente. Al mitigar el riesgo de la pérdida resultante de un impago, el otorgante tendrá mayores posibilidades de obtener el préstamo y, con bastante frecuencia, en condiciones más favorables.

28. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se adopta un enfoque funcional integrado y global de las operaciones garantizadas a fin de abarcar cualquier tipo de derecho de propiedad sobre un bien mueble que sirva para garantizar la ejecución de una obligación independientemente de la forma de la operación, el tipo del bien gravado, el carácter de la obligación garantizada o la condición de las partes (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo I, párrs. 101 a 112, y recomendaciones 2 y 10). Por consiguiente, el concepto de “garantía real” no se limita a los tipos de dispositivos de garantía reconocidos convencionalmente por los distintos ordenamientos jurídicos, tales como la prenda, el gravamen o la hipoteca mobiliaria. También abarca cualquier tipo de derecho de propiedad, incluido el dominio, que funcione como garantía, tal como el derecho a la retención de la titularidad para garantizar el pago del precio de compra de un bien, el derecho al arrendamiento financiero, el derecho de un cesionario de una transmisión de bienes para fines de garantía y su derecho a los créditos por cobrar con fines de garantía (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo I, párrs. 101 a 112 y recomendaciones 2, 8 y 9).

29. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* adopta un enfoque del concepto de la garantía en el que prima el fondo sobre la forma a fin de asegurar que los derechos legales de las partes inmediatas y cualesquiera terceros afectados por un acuerdo de garantía estén sujetos al mismo conjunto uniforme de normas jurídicas. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que, en la medida en que se reconozcan excepciones por razones de política general (por ejemplo, para proteger a los compradores de bienes de consumo de valor relativamente bajo), dichas excepciones sean limitadas y estén claramente especificadas en el régimen (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 4 y 7).

3. Constitución de una garantía real

30. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que se haga una distinción entre la constitución de una garantía (validez entre el otorgante y el acreedor garantizado) y su oponibilidad a terceros (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo I, párrs. 1 a 7, capítulo III, párrs. 6 a 8 y recomendaciones 1, apartado c), 13 y 30). La principal razón para adoptar este enfoque es la de alcanzar uno de los objetivos clave de un régimen de operaciones garantizadas eficaz y eficiente, es decir, un régimen que permita a las partes constituir una garantía sobre sus bienes de manera sencilla y eficiente reduciendo al

mínimo las formalidades relacionadas con la constitución de una garantía (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 1, apartado c), y 13).

31. De este modo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* contiene varias disposiciones que tienen por objeto lograr este objetivo. En efecto, recomienda que: a) se constituya la garantía simplemente por acuerdo entre el otorgante y el acreedor garantizado; b) se concierte el acuerdo por escrito si no va acompañado de una transmisión de la posesión efectiva del bien gravado al acreedor garantizado; c) el requisito de concertarlo por escrito sea flexible e incluya los medios electrónicos de las comunicaciones y se exija solamente la firma del otorgante; y d) que el acuerdo refleje la intención de las partes de constituir una garantía real, identifique a las partes y describa la obligación garantizada y los bienes gravados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 14 y 15).

32. Al prescindir de la imposición de la transmisión de la posesión de los bienes gravados para constituir una garantía real, el régimen de operaciones garantizadas previsto por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* permite a una empresa gravar no solo sus bienes corporales existentes sino también sus bienes inmateriales y futuros, así como la masa de bienes en circulación, incluidos, lo cual es muy importante, los créditos por cobrar y las existencias (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo II, párrafos 49 a 70 y recomendaciones 2 y 17). Con arreglo a las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, se constituye una garantía real sobre bienes futuros no bien el otorgante adquiere derechos sobre esos bienes (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 13). Gracias a este enfoque, es probable que aumente el acceso al crédito al ampliarse la gama de bienes que puede ofrecer un otorgante como garantía. Las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* confirman además que la garantía puede utilizarse para respaldar cualquier tipo de obligación, incluidas las obligaciones futuras o indeterminadas (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 16).

33. El reconocimiento por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* de las garantías reales no posesorias también facilita el acceso del consumidor al crédito puesto que permite a los otorgantes que son también consumidores tomar posesión inmediata de los bienes adquiridos con un crédito garantizado. Sin embargo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* tiene en cuenta la necesidad de preservar los derechos del consumidor o de otras personas que puedan necesitar protección especial. Por consiguiente, se recomienda que el régimen de las operaciones garantizadas no afecte a los derechos de los consumidores con arreglo a la legislación de protección al consumidor o deje sin efecto los límites legales relacionados con cualquier tipo particular de bienes que puedan ser transmitidos o gravados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo I, párrafos 10 y 11, capítulo II, párrafos 56, 57 y 107, recomendaciones 2, apartado b), y 18).

34. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* también confirma que una garantía real se mantiene automáticamente sobre cualquier producto de los bienes gravados (y el producto del producto) sin necesidad de concertar un acuerdo especial (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 19). Este enfoque está en armonía con las expectativas de las partes. Si la garantía real no se hiciera extensiva al producto, una transmisión autorizada de los bienes gravados podría anular o reducir considerablemente la capacidad de esos bienes para garantizar la deuda. Aun cuando la garantía real siga a los bienes gravados en manos

de un cesionario, la extensión de la garantía real al producto tiene sentido puesto que proporciona una mayor seguridad, en particular en los casos en que el producto sea de más valor que el bien gravado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo II, párrafos 72 a 81).

4. Oponibilidad a terceros de una garantía real

35. Con arreglo a las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, una garantía real se vuelve exigible entre las partes no bien se cumplen los requisitos reseñados *supra*. Sin embargo, no se puede constituir una garantía real en oposición a derechos adquiridos por terceros sobre los bienes gravados a menos y hasta que se satisfagan los requisitos de oponibilidad a terceros de la garantía real. El propósito de esta distinción es asegurar que la garantía real constituida por un acuerdo privado entre las partes se dé a conocer públicamente a terceros que pudieran resultar afectados adversamente por su existencia.

36. La inscripción de una notificación en un registro general de las garantías reales es el método principal reconocido por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* para lograr la oponibilidad a terceros de una garantía real (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 32). Si bien este es el único método de que se dispone para todos los tipos de bienes gravados, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce la existencia de otros métodos según el tipo de bien gravado.

37. En primer lugar, se considera que la transmisión de la posesión de los bienes gravados al acreedor garantizado o su representante constituye suficiente notificación práctica a los terceros de que es probable de que dichos bienes estén gravados. Por consiguiente, se estima que la desposesión del otorgante constituye un método alternativo de lograr la oponibilidad a terceros siempre que la desposesión sea efectiva (no deducible, ficticia, supuesta o simbólica; véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, sección B, “posesión” y recomendación 37). Resulta evidente que este método de lograr la oponibilidad a terceros puede emplearse solamente en el caso de los bienes corporales de que es propietario en el momento el otorgante y cuya posesión está dispuesto a ceder para todos los fines prácticos.

38. En segundo lugar, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que, en los casos en que el bien gravado garantice el derecho al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria o un derecho a recibir el producto de una carta de crédito, los acreedores garantizados tendrán la opción de lograr la oponibilidad a terceros tomando “control” del bien gravado en lugar de hacer la inscripción en el registro general de las garantías reales (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, secc. B, “control” y recomendación 103). Cabe observar que las garantías reales y los derechos de pago nacidos en virtud de contratos financieros regidos por acuerdos de compensación global y operaciones con divisas no están incluidos en el ámbito de aplicación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 37 a 39, y recomendación 4, apartados c) a e)). Para estos tipos de bienes, lo normal será que el Estado promulgante desee proporcionar también métodos alternativos de lograr la oponibilidad a terceros.

39. En tercer lugar, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* puede aplicarse a las garantías reales sobre tipos de bienes que están sujetos a un régimen especial de inscripción registral, por ejemplo, los vehículos automotores, los buques, las aeronaves y la propiedad intelectual (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 32 a 36, y recomendación 4, apartados a) y b)). En la medida en que la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* es aplicable a las garantías reales sobre estos tipos de bienes, recomienda que se reconozca la inscripción en el registro especializado como método alternativo de lograr la oponibilidad a terceros (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 38).

40. En cuarto lugar, en los casos en que el bien gravado está o pueda estar incorporado a un bien inmueble de manera que forme parte de una propiedad inmobiliaria, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la garantía real sobre el bien gravado pueda hacerse oponible a terceros mediante la inscripción de una notificación sea en el registro general de las garantías reales o en el registro de la propiedad inmobiliaria (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 43). Cabe observar que los requisitos relativos a la descripción del bien gravado para que la inscripción surta efecto pueden diferir según dónde se efectúe la inscripción de la notificación debido a las diferencias en la forma en que los dos tipos de registro organizan las inscripciones. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que se considere suficiente la descripción de un bien gravado en una notificación inscrita en el registro general de las garantías reales si permite su identificación con certeza razonable puesto que las notificaciones de ese registro están organizadas, no por la descripción del bien, sino por el identificador del otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, apartado b)). Las inscripciones en un registro de la propiedad inmobiliaria, en cambio, suelen estar organizadas por remisión a un identificador específico para el solar o terreno de que se trate. Por consiguiente, el identificador utilizado para identificar el solar donde se encuentra la propiedad inmobiliaria al cual está incorporado o estará incorporado el bien gravado tendrá que incluirse también en la notificación que se inscriba en el registro de la propiedad inmobiliaria.

5. Prelación de una garantía real

a) Garantías reales concurrentes

41. Si se han hecho oponibles a terceros más de una garantía real constituida por el mismo otorgante sobre el mismo bien gravado, es necesario tener una norma de prelación para ordenar las garantías reales concurrentes entre sí (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párrs. 12 a 14). En los casos en que las garantías reales concurrentes se hicieron, todas ellas, oponibles a terceros mediante inscripción registral, la prelación se determina en general por el orden de inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 76, apartado a)). En los casos en que las garantías reales concurrentes se hicieron, todas ellas, oponibles a terceros por métodos distintos de la inscripción registral, la prelación se determina por el grado de eficacia frente a terceros (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 76, apartado b)). En caso de que una garantía real que se hizo oponible a terceros por métodos distintos de la inscripción registral (por ejemplo, por entrega del bien) compita con una garantía real que

adquirió su eficacia frente a terceros por inscripción registral, la prelación se determina generalmente por el orden respectivo de la inscripción registral o la oponibilidad a terceros (por ejemplo, entrega del bien), según cuál haya ocurrido primero (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 76, apartado c)).

42. Si bien estas recomendaciones proporcionan las normas básicas, un régimen moderno sobre las operaciones garantizadas del tipo recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconocerá, invariablemente, algunas excepciones a fin de facilitar otras prácticas comerciales y la consecución de objetivos normativos. A continuación se resumen las principales excepciones reconocidas por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

43. En primer lugar, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce que ha de concederse prelación especial al acreedor garantizado que financie la adquisición por el otorgante de bienes corporales (por ejemplo, bienes de consumo, equipo o existencias) o propiedad intelectual (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo X, párrafos 125 a 139, y el *Suplemento*, párrafos 181 a 183. Siempre que se cumplan los requisitos recomendados por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* para obtener esta prelación especial, la garantía real del pago del “precio de una adquisición” tendrá prelación con respecto al valor de esos bienes por encima de las garantías reales del otorgante sobre bienes futuros de ese tipo que fueron adquiridos previamente e inscritos en un registro o que se hicieron oponibles a terceros de otro modo. Este enfoque no perjudica al acreedor garantizado anterior puesto que el otorgante no habría podido adquirir esos nuevos bienes de no ser por la nueva financiación (y el acreedor garantizado podría, primero, concertar un acuerdo de garantía, verificar el registro, esperar un breve lapso y, finalmente, desembolsar los fondos). El dar prelación a las garantías reales de adquisición beneficia también al otorgante al brindarle acceso a fuentes diversificadas de crédito garantizado para financiar las nuevas adquisiciones.

44. En segundo lugar, una garantía real sobre una suma monetaria o sobre títulos negociables o documentos negociables que se vuelva oponible a terceros mediante la transmisión de la posesión al acreedor garantizado tiene prelación sobre una garantía real que se hubiera hecho oponible a terceros previamente mediante inscripción registral (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 101, 102, 108 y 109). Esta excepción se basa en el principio de que conviene preservar la libre negociabilidad de estos tipos de bienes en el mercado.

45. En tercer lugar, cuando el bien gravado es el derecho al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria o el derecho a recibir el producto de una carta de crédito, un acreedor garantizado que obtenga prelación al tomar “control” del bien gravado tendrá prelación sobre una garantía real anterior o posterior que se haya hecho oponible a terceros mediante inscripción registral (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, sección B, “control” y recomendaciones 103 y 107). Como ya se dijo (véase el párrafo 38, *supra*), las garantías y los derechos de pago nacidos en virtud de contratos financieros regidos por acuerdos de compensación global y de operaciones con divisas no se incluyen en el ámbito de aplicación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo I, párrafos 37 a 39 y recomendación 4,

apartados c) a e). Los Estados promulgantes deberán establecer normas especiales de prelación en relación con estos tipos de bienes.

46. En cuarto lugar, en la medida en que el régimen de las operaciones garantizadas se aplique a las garantías reales sobre tipos de bienes muebles que estén sujetos a sistemas de registro especializados como, por ejemplo, los vehículos automotores, los buques, las aeronaves y la propiedad intelectual (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo I, párrafo 32 a 36 y recomendación 4, apartados a) y b)), la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que se dé prelación a toda garantía real que se haya hecho oponible a terceros mediante la inscripción en el registro especializado en contraposición a una garantía real inscrita en el registro general; y en el caso de que las dos garantías reales estén inscritas en el registro de la propiedad inmobiliaria, la prelación deberá determinarse por el orden de inscripción registral (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 77 y 78). Estas normas tienen por objeto preservar la integridad y exhaustividad del fichero del registro especializado.

47. En quinto lugar, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda un enfoque similar para determinar la prelación de las garantías reales concurrentes sobre bienes incorporados a un bien inmueble. Más concretamente, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que se dé prioridad a toda garantía real cuya notificación se haya inscrito en el registro de la propiedad inmobiliaria, con preferencia a una garantía real sobre el bien incorporado cuya notificación se haya inscrito solamente en el registro general de las garantías reales; y en los casos en que la inscripción registral con respecto a las garantías reales concurrentes sobre el bien incorporado o el bien inmueble se haya hecho en el registro de la propiedad inmobiliaria, la prelación se determinará por el orden de inscripción registral (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 87 y 88). Estas normas tienen por objeto preservar la integridad y exhaustividad del fichero del registro de la propiedad inmobiliaria.

(A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 22º período de sesiones

[Original: inglés]

ADICIÓN

Índice

Párrafos

Introducción (<i>continuación</i>)	
E. Información general sobre el régimen de garantías reales y la función de la inscripción registral (<i>continuación</i>)	1-39
5. Prelación (<i>continuación</i>)	1-15
6. Amplitud de las inscribibles en el registro	16-19
7. Consideraciones relativas al conflicto de leyes	20-21
8. Inscripción registral de la notificación	22-31
9. Función de la inscripción registral y sus consecuencias jurídicas	32-33
10. Coordinación con los registros especiales de bienes muebles	34-36
11. Coordinación con los registros de la propiedad inmobiliaria	37-39
I. Creación y funciones del registro de garantías reales	40-55
A. Observaciones generales	40-55
1. Creación del registro de garantías reales	40
2. Nombramiento del director del registro	41
3. Funciones del registro	42
4. Otras consideraciones relativas a la creación del registro	43-45
5. Condiciones de uso del registro	46-47
6. Registro electrónico o de documentos en papel	48-55
B. Recomendaciones 1 a 3	
II. Acceso a los servicios del registro	56-61
A. Observaciones Generales	56-61
1. Acceso del público	56-58
2. Días y horas de funcionamiento del registro	59-61

Introducción (*continuación*)

E. Información general sobre el régimen de garantías reales y la función de la inscripción registral (*continuación*)

5. Prelación (*continuación*)

b) Compradores u otros cesionarios de bienes gravados

1. Por regla general, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce que todo acreedor garantizado que haya cumplido con los requisitos de la oponibilidad a terceros respecto de su garantía real tiene el “derecho a seguir” el bien gravado cuando pasa a manos de un comprador u otro arrendatario del otorgante, que adquiere derechos sobre el bien gravado (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. II, párrs. 72 a 89, cap. III, párrs. 15, 16 y 89, y recomendación 79). Por otro lado, el arrendatario recibirá el bien gravado libre de una garantía real si esta no se ha vuelto oponible a terceros mediante la inscripción registral u algún otro método aun cuando dicho arrendatario tenga conocimiento real de la existencia de la garantía. Este enfoque no es injusto con los acreedores garantizados puesto que podría haberse protegido mediante la inscripción registral oportuna o adoptando otras medidas para hacer que la garantía real fuera oponible a terceros.

2. Sin embargo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce haber excepciones a esta regla general. A continuación se resumen las principales.

3. En primer lugar, un comprador o arrendatario o licenciataria que adquiera un bien gravado con el consentimiento del acreedor garantizado adquiere el bien libre de todo gravamen sin que lo afecte la garantía real (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 80). Este enfoque facilita las operaciones que cuentan con la aprobación del acreedor garantizado, normalmente después de adoptarse ciertas medidas para proporcionar otras garantías al acreedor garantizado.

4. En segundo lugar, un comprador o arrendatario o licenciataria que adquiera un bien gravado en el curso ordinario de los negocios del otorgante, lo adquiere libre de todo gravamen aun cuando el acreedor garantizado haya inscrito una notificación de la garantía real o cumplido de cualquier otro modo con los requisitos de la oponibilidad a terceros (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 81). Este enfoque es compatible con toda expectativa comercial razonable de las partes. No sería realista esperar que los compradores de bienes ofrecidos por una empresa vendedora de ese tipo de bienes en que está interesado el comprador, por ejemplo, equipo informático, consulten el registro para averiguar si tales artículos a la venta están o no gravados. Por lo demás, un acreedor garantizado que haya aceptado una garantía real sobre las existencias de un otorgante lo hará normalmente en el entendimiento de que el otorgante podrá enajenar sus existencias, libres de todo gravamen, en el curso normal de su negocio. De hecho, para que el otorgante pueda obtener los ingresos requeridos para reembolsar el préstamo garantizado, sus clientes deberán sentirse legalmente seguros de que todo bien que adquieran del otorgante en el curso normal de su negocio estará libre de todo gravamen.

5. En tercer lugar, la misma política de preservación de la negociabilidad que justifica el otorgar una prelación especial al acreedor garantizado que toma posesión

física de un bien gravado en la forma de dinero o documentos negociables (por ejemplo, un conocimiento de embarque) o títulos negociables (como un cheque) también justifica que se les dé prelación a los cesionarios directos de estos tipos de bien gravado (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 101, 102, 108 y 109).

6. En cuarto lugar, como ya se dijo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* puede aplicarse a bienes que se encuentran sujetos a régimen de inscripción registral especializado, como los vehículos automotores, buques, aeronaves y la propiedad intelectual (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 32 a 36 y recomendación 4, apartados a) y b)). Estos registros normalmente cumplen funciones más amplias que la de simplemente dar a conocer las garantías reales sobre los bienes pertinentes, y, en particular, de hacer constar la propiedad o transmisión de la propiedad. Por consiguiente, en la medida en que la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se aplica a las garantías reales sobre estos tipos de bien, recomienda que se dé prelación a un comprador u otros cesionario y que haya hecho una inscripción en el registro especializado con preferencia a la garantía real inscrita en el registro general de garantías reales; y en el caso de que la garantía real esté también inscrita en el registro especializado, se determinará la prioridad según el orden de inscripción (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 77 y 78).

7. En quinto lugar, se adopta un enfoque semejante cuando se trata de determinar la prelación con respecto a garantías reales sobre bienes incorporados a bienes inmuebles. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que se dé prelación al comprado y otro cesionario del bien inmueble de que se trate inscrito en el registro de la propiedad inmobiliaria con preferencia a la garantía real sobre el bien incorporado inscrito solamente en el registro general de garantías reales. Y en caso de que la garantía real sobre el bien incorporado también esté inscrita en el registro de la propiedad inmobiliaria, se determinará el orden de prelación por la fecha de inscripción registral (*Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 87 y 88).

c) Acreedores no garantizados del otorgante

8. Una de las principales ventajas de obtener una garantía es que permite al acreedor garantizado a hacer valer su derecho a percibir el valor realizable de los bienes gravados con preferencia a los derechos de los acreedores no garantizados del otorgante. En consecuencia, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que una garantía real tenga prelación sobre los derechos de un acreedor no garantizado siempre que el acreedor garantizado haya hecho una inscripción registral o, de otro modo, haga que su garantía real sea oponible a terceros antes de que el acreedor no garantizado obtenga una decisión judicial o una orden judicial provisional contra el otorgante y adopta las medidas necesarias con arreglo a la ley aplicable del Estado promulgante para adquirir derechos sobre los bienes gravados (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 84). Este enfoque permite al acreedor no garantizado de terminar la medida en que los bienes de sus deudores pueden estar gravados a fin de decidir si vale la pena o no obtener una decisión judicial o emprender un proceso ejecutorio judicial. Sin embargo, la norma de la prelación está sujeta a una importante reserva. Aun cuando el acreedor garantizado haya inscrito la notificación de su garantía real o logre por otros

métodos la oponibilidad a terceros después que el acreedor no garantizado adquiriera derechos sobre los bienes gravados de su deudor, el acreedor garantizado tendrá prelación en la medida del crédito que haya extendido por adelantado antes de haber tomado conocimiento real de que el acreedor no garantizado ha adquirido derechos sobre los bienes gravados o, con arreglo a un compromiso anterior e irrevocable extienda un crédito al otorgante (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. V, párrs. 94 a 106, y recomendación 84).

9. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* examina, pero sin hacer ninguna recomendación al respecto, las medidas que debe adoptar un acreedor no garantizado para adquirir derechos sobre los bienes de su deudor para tener posibilidades de prevalecer sobre un acreedor garantizado que no haya logrado la oponibilidad a terceros en absoluto o a su debido tiempo (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. V, párrs. 94 a 106). Esto se deja a la ejecución judicial y el régimen de las ejecuciones judiciales del Estado promulgante. En algunos Estados, un acreedor no garantizado adquiere derechos sobre los bienes de su deudor solamente una vez que se ha terminado el proceso de ejecución judicial mediante la incautación y venta y los derechos del acreedor judicial se extienden al producto de la venta. En otros Estados, un acreedor no garantizado, al obtener una sentencia ejecutoria puede conseguir el equivalente de una garantía real general sobre los bienes muebles presentes y futuros del deudor por sentencia judicial simplemente inscribiendo una notificación de la sentencia en el registro general de garantías reales. En consecuencia, los Estados promulgantes que adopten las recomendaciones generales de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* deberán tener en cuenta el régimen existente en la materia y decidir cual es el enfoque más apropiado.

d) El representante de la insolvencia

10. En general, los regímenes modernos de la insolvencia respetan la prelación a que tienen derecho los acreedores garantizados en virtud de la ley en caso de que se inicien procedimientos de insolvencia contra el otorgante. Este es el criterio recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 239) en consonancia con lo dispuesto en la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia (la “Guía de la Insolvencia”). De ello se desprende que, en general, un acreedor garantizado tendrá prelación sobre las reclamaciones de los acreedores no garantizados de un otorgante insolvente, siempre que haya hecho una inscripción registral o cumplido, de otro modo, los requisitos del régimen de operaciones garantizadas para lograr la oponibilidad a terceros antes de la iniciación de los procedimientos de insolvencia. En caso contrario, si el acreedor garantizado no inscribe la notificación o se asegura de otro modo que su garantía real sea oponible a terceros antes de la iniciación de los procedimientos de insolvencia, por lo general, el resultado será que el acreedor garantizado quede relegado en la práctica a la categoría de acreedor no garantizado. Este enfoque alienta a hacer la inscripción a su debido tiempo o adoptar otras medidas para lograr la oponibilidad a terceros por los acreedores garantizados. Ello también permite al representante de la insolvencia del otorgante determinar eficientemente qué bienes del otorgante pueden haber estado efectivamente gravados.

11. Sin embargo, la inscripción registral a su debido tiempo no protege a un acreedor garantizado de toda medida impugnatoria fundada en ciertas reglas

generales del régimen de la insolvencia, como las que declaran la nulidad de toda sesión preferencial o fraudulenta y las que otorgan prelación a determinadas categorías protegidas de acreedores (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. XII, y recomendación 239; véase también *Guía de la Insolvencia* recomendaciones 88 y 188).

12. Una garantía real que era oponible a terceros en el momento de iniciarse los procedimientos de insolvencia podría perderse posteriormente, por ejemplo, porque se consiguió la oponibilidad a terceros mediante la inscripción registral y el plazo de vigencia de esa inscripción ha vencido. Para prevenirse contra este riesgo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que todo acreedor garantizado tenga derecho a iniciar las acciones necesarias con arreglo al régimen de operaciones garantizadas a fin de preservar la oponibilidad de su garantía real a terceros, aun cuando se hayan iniciado procedimientos de insolvencia (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 238). Esta recomendación tiene por objeto asegurar que ningún acreedor garantizado se vea privado de la facultad de mantener su prelación como resultado de una suspensión automática de la acción ejecutoria, que se impone normalmente al iniciarse los procedimientos de insolvencia.

13. En los casos de procedimiento de insolvencia adopta la forma de una reorganización, los regímenes modernos de insolvencia autorizan, en general, al otorgante insolvente a constituir una garantía real a fin de obtener financiación posterior a la apertura (véase *Guía de la Insolvencia*, recomendación 65). Con arreglo a la *Guía de la Insolvencia*, una garantía real de este tipo no tiene prioridad sobre ningún acreedor garantizado existente a menos que así lo hayan acordado entre sí o haya sido autorizado por el Tribunal con las protecciones apropiadas para ellos. Cuando se establece financiación posterior a la apertura, se vuelven aplicables las normas del régimen de operaciones garantizadas que rigen la oponibilidad de las garantías reales a terceros.

e) Créditos privilegiados

14. Por distintas razones de política, el régimen de operaciones garantizadas o el régimen de la insolvencia, o ambos, de un Estado pueden conceder un grado de prelación preferente respecto de los créditos de los acreedores garantizados a ciertas categorías especificadas de acreedores no garantizados. Entre los ejemplos típicos cabe mencionar los créditos del Estado promulgante respecto del pago de impuestos y de los empleados respecto de los pagos de sus sueldos u otras prestaciones laborales. Además, en el contexto de la insolvencia, algunos Estados apartan una parte especificada del valor de los bienes gravados, especialmente de los bienes empresariales, en favor de los acreedores no garantizados con preferencia a los acreedores garantizados. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* examina los créditos privilegiados y recomienda, en la medida en que el Estado promulgante decida mantenerlos, en mayor o menor medida, deberían de estar limitados tanto en cuanto al tipo como al monto y estar previstos en el régimen de operaciones garantizadas y el de la insolvencia, según el caso, de manera precisa y específica (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. V. párrs. 90 a 93, y cap. XII, párrs. 59 a 63, y recomendaciones 83 y 239). Hay dos razones por las cuales la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* sigue este enfoque; por un lado, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* tienen en cuenta las políticas sociales que los Estados

promulgante pueden desear poner en práctica mediante los créditos privilegiados. Por otro lado, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce que los créditos privilegiados pueden tener influencia en el costo y la oferta del crédito.

15. En algunos Estados, los créditos privilegiados pueden inscribirse en el registro general de garantías reales si bien en esos Estados en las normas de inscripción registral y prelación aplicables a las garantías reales pueden aplicarse necesariamente a los créditos privilegiados. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* examina, pero sin hacer ninguna recomendación al respecto, la cuestión de si los créditos privilegiados deben inscribirse y cuáles han de ser las consecuencias, para la prelación, de la inscripción registral (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. V, párr. 90).

6. Amplitud de las inscribibles en el registro

a) Cesión pura y simple

16. Como ya se explicó (véase A/CN.9/WG.VI/WP.52, párrs. 27 a 29), el régimen de garantías reales previsto en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* es de un amplio ámbito de aplicación y abarca todas las operaciones que funcionan, en definitiva, para garantizar una obligación, independientemente del carácter formal de la garantía real del acreedor garantizado, el tipo de bien gravado, la índole de la obligación garantizada o la condición de las partes (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 101 a 112, y recomendaciones 2 y 10).

17. Además de ser aplicable a todas las operaciones garantizadas definidas en el sentido funcional, integrado y amplio que acaba de reseñarse, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el régimen de operaciones garantizadas sea aplicable también, por lo menos en cierta medida, a la cesión pura y simple de créditos por cobrar. Sin embargo, el colocar la cesión pura y simple dentro del ámbito de aplicación del régimen de operaciones garantizadas no significa que esas operaciones se hayan redefinido como operaciones garantizadas, más bien, se procura con ello asegurarse de que el destinatario de una cesión pura y simple de créditos por cobrar esté sujeto a las mismas normas relacionadas con la constitución de las garantías, la oponibilidad a terceros y el orden de prelación (pero no, en general, con la ejecución) y que el tenedor de una garantía real sobre créditos por cobrar. Se asegura también de este modo que el destinatario de una cesión pura y simple tenga los mismos derechos y obligaciones frente al deudor de créditos por cobrar que un acreedor garantizado (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 25 a 31, y recomendaciones 3 y 167).

18. Con arreglo a este enfoque, el cesionario, por lo general, tendrá que inscribir una notificación de su garantía en el registro de garantías reales para que la cesión sea oponible a terceros; y el orden de prelación entre las garantías de los sucesivos cesionarios o acreedores garantizados concurrentes que hayan adquirido derechos sobre los mismos créditos por cobrar del mismo cedente u otorgante se determinarán según el orden en que hayan sido inscritas (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* cap. III, párrs. 43). La razón para adoptar este enfoque es que la cesión pura y simple de créditos por cobrar no solo desempeña una función de financiación sino que crea también el mismo problema de insuficiencia de información frente a terceros como las garantías reales sobre créditos por cobrar a menos que se inscriba una notificación en el registro de garantías reales como

condición de oponibilidad a terceros, un posible acreedor garantizado o cesionario u otro tercero carecerían de medios eficientes para verificar si los créditos por cobrar adeudados a una empresa ya han sido cedidos o de haber sido cedidos, si la cesión consiste en una cesión pura y simple en una cesión a efectos de garantía. Si bien es cierto que podría indagarse entre los deudores de los créditos por cobrar ello no resulta factible en la práctica si los deudores de los créditos por cobrar no han sido notificados de la cesión o si la operación abarca créditos por cobrar presentes y futuros en general.

b) Otras operaciones no garantizadas

19. El simple arrendamiento a largo plazo y las ventas en consignación de bienes muebles no funciona de manera de garantía del precio de adquisición de bienes y, por consiguiente, no pueden considerarse garantías reales que queden comprendidas dentro del ámbito de aplicación del régimen de las garantías reales previsto en *la Guía de las Operaciones Garantizadas*. Sin embargo, plantean los mismos problemas de publicidad frente a terceros que las garantías reales no posesorias puesto que entrañan una separación de la titularidad del bien (del arrendador o del consignador del bien) de su posesión efectiva (hermanos del arrendatario o consignatario). Para remediar este problema, algunos Estados extienden a estos tipos de operación el régimen de operaciones garantizadas (a excepción de la ejecución) tal como se aplica a las garantías reales para financiar adquisiciones a estos tipos de operación. Además de garantizar una publicidad adecuada para los terceros, este enfoque disminuye también el riesgo de litigios en cuanto a si una operación en forma de arrendamiento o venta en consignación es, en realidad, una garantía real y, por tanto, carecerá de validez si no se ha hecho la inscripción registral correspondiente o queda subordinada en el orden de prelación si las normas que rigen la prelación especial concedida a las garantías reales para financiar la adquisiciones no son aplicables. La *Guía de las Operaciones Garantizadas* examina la cuestión pero sin formular ninguna recomendación (véase *Guía de las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párr. 44). Cabe observar, con todo, que si el arrendador o el consignador tienen temor de perder la oponibilidad a terceros o el orden de prelación en caso de que su garantía se caracterice como garantía real, le queda el recurso de hacer una inscripción registral cautelar a fin de evitar toda impugnación de la oponibilidad de sus garantías a terceros.

7. Consideraciones relativas al conflicto de leyes

20. En situaciones en que una operación garantizada guarda relación con más de un Estado, los acreedores garantizados y los terceros necesitan clara orientación sobre la ley de cual Estado es aplicable a las operaciones. Con arreglo al enfoque del conflicto de leyes recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* la ley aplicable depende del carácter de los bienes gravados. Por ejemplo, la ley aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real sobre bienes corporales es, por lo general, la ley del Estado en que se encuentra el bien gravado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 203). Esto significa que, en caso de que un acreedor garantizado desee asegurarse de que su garantía real es oponible a terceros mediante la inscripción registral, deberá inscribir la notificación de su garantía real en el registro del Estado donde se encuentre el bien gravado. De ello se desprende que, en caso de que los bienes gravados se encuentren en múltiples Estados, en general, será preciso

hacer varias inscripciones, con respecto a las garantías reales sobre bienes inmateriales y bienes muebles y que se utilizan de ordinario en múltiples jurisdicciones, la ley aplicable será la ley del Estado en que se encuentre el otorgante (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 208). Por consiguiente, el acreedor garantizado deberá inscribir una notificación de su garantía real en el registro del Estado donde se encuentra el otorgante si pretende lograr la oponibilidad a terceros mediante la inscripción registral.

21. Las reglas que se acaban de reseñar son las reglas básicas. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda distintas reglas especializadas sobre el conflicto de leyes respecto de las garantías reales sobre determinados tipos de bienes. Entre ellos cabe mencionar: a) bienes, las garantías sobre los cuales estén sujetas a inscripción en un registro especial; b) los créditos por cobrar nacidos de una operación relacionada con bienes inmuebles; c) garantías sobre el pago de fondos acreditados en cuentas bancarias; d) derechos a recibir el producto de una promesa independiente; y e) derechos de propiedad intelectual (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 204 a 207, 209 a 215 y 248). Así, por ejemplo, cuando el bien gravado sea un derecho de propiedad intelectual, la ley aplicable será, en primer lugar, la ley del Estado que protege la propiedad intelectual, si bien una garantía real que se constituya y haga oponible a terceros solo con arreglo a la ley del Estado en que se encuentra el otorgante puede tener eficacia todavía contra el representante de la insolvencia del otorgante y los acreedores judiciales (véase *Suplemento*, recomendación 248).

8. Inscripción registral de la notificación

22. La mayoría de los Estados han establecido registros para inscribir la titularidad de los bienes inmuebles y los gravámenes que pesan sobre ellos. Muchos Estados han establecido también registros similares de la propiedad para un número limitado de bienes inmuebles de alto valor, como buques y aeronaves. Es esencial, para la creación con éxito del tipo de registro de las garantías reales previsto en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* que sus características, profundamente diferentes, se han comprendidas claramente con los responsables de su diseño y funcionamiento, así como por sus usuarios potenciales.

23. En primer lugar, a diferencia de los registros catastrales, de buques o aeronaves, el registro general de garantías reales previsto en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no pretende registrar la titularidad del bien gravado descrito en la notificación inscrita, ni la transmisión de esa titularidad, ni siquiera garantizar que la persona designada, como otorgante en la notificación inscrita sea el auténtico propietario del bien gravado a su nombre. El registro deja meramente constancia fidedigna de los gravámenes que tal vez pesen sobre todo bien de la índole descrita que el otorgante posea o pueda llegar a poseer a raíz de operaciones comerciales o de hechos de los que el registro no deja constancia (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 10 a 14).

24. En segundo lugar, los registros de la propiedad suelen obligar al solicitante de la inscripción a presentar a examen o a hacer inscribir la documentación probatoria de su titularidad. Ello se debe a que la inscripción en esos registros constituye prueba firme o, al menos, presuntiva de la titularidad del bien inscrito o de todo derecho real o gravamen que pese sobre dicho bien.

25. Aunque algunos registros de garantías reales en algunos Estados exigen que se presente la documentación que subyace a la garantía, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que los Estados adopten un sistema de inscripción registral de la notificación más que de la inscripción de un documento (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 54, apartado b) y 57). Un sistema de inscripción registral de las notificaciones no exige ni que la documentación probatoria de la garantía real sea inscrita ni que sea siquiera sometida al examen del personal del registro. Bastará con hacerla inscribir los datos básicos requeridos para alertar a todo autor de una consulta acerca de la posibilidad de que los bienes descritos en la notificación estén gravados. Eso quiere decir que la inscripción de la notificación de una garantía real no da fe de que ese gravamen exista sino que advierte de su posible existencia actual o futura. Como ya se explicó (véanse A/CN.9/WG.VI/WP.52, párrs. 30 y 36), la inscripción de una notificación no tiene nada que ver con la constitución de una garantía real; simplemente hace que cualquier garantía real constituida mediante un acuerdo de garantía, que no consta en el registro, entre las partes oponibles a terceros siempre que se hayan cumplido otros requisitos para la constitución del acuerdo reseñados *supra* (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 32, 33 y 67).

26. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda el sistema de la inscripción de notificaciones más que la inscripción de documentos debido a que la inscripción registral de la notificación:

a) Reduce el costo de la operación para los autores de inscripciones (pues no necesitan inscribir o proporcionar pruebas de la documentación relativa a la garantía a fin de hacer la inscripción) y para los terceros que consultan al registro (pues no necesitan examinar lo que podría ser una voluminosa documentación del acuerdo de garantía para determinar si la garantía real existe sobre los bienes pertinentes);

b) Alivia la labor administrativa y de archivo requerida del personal del registro para su funcionamiento;

c) Reduce los riesgos de error (cuanto menos datos se inscriban menor será el riesgo de error en su inscripción); y

d) Ampara mejor la privacidad del acreedor garantizado y del otorgante (cuanta menos información haya de facilitarse menor será la información confidencial a la que podrá acceder quien haga una búsqueda).

27. Puesto que la inscripción en un sistema de inscripción registral de notificaciones no significan necesariamente que exista efectivamente una garantía real, los terceros con garantías concurrentes sobre los bienes gravados querrán pruebas, normalmente, de la existencia de un acuerdo de garantía válido entre las partes y el alcance de los bienes abarcados por dicho acuerdo. Lo mismo vale aun cuando la presunta garantía real se haya vuelto oponible a terceros por algún otro método, como la transmisión de posesión, puesto que la posesión por el acreedor garantizado putativo puede obedecer a fines distintos de la garantía.

28. Algunos Estados prevén un procedimiento por el cual un tercero con un derecho de propiedad sobre un bien gravado puede solicitar esta información directamente de la persona nombrada como acreedor garantizado en una inscripción o la persona que como por lo demás, afirma tener esa condición. El mismo derecho

se hace extensivo a los acreedores no garantizados del otorgante para permitirles decidir si vale la pena o no que incurran en los gastos de obtener una decisión judicial y emprender la ejecución contra los bienes del deudor. Si bien la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no formula ninguna recomendación al respecto, se deja abierta la posibilidad al deudor de pedir al acreedor garantizado que envíe la información pertinente directamente a un tercero. Sin embargo, el deudor o el acreedor garantizado pueden no sentirse inclinados a cooperar en cuyo caso el tercero necesitará obtener un mandamiento judicial con arreglo a otra ley.

29. Aun en los Estados que permiten a los terceros exigir la verificación de la existencia de una garantía real y su alcance directamente del acreedor garantizado, este derecho no se aplica a los posibles compradores o posibles acreedores garantizados. Pueden ampararse simplemente negándose a comprar o a extender el crédito garantizado a menos que la inscripción registral relacionada con la garantía real sea cancelada o el acreedor garantizado putativo está dispuesto a comprometerse que no tiene intención de hacer valer ni en el presente ni en el futuro ninguna garantía real sobre el bien objeto de su interés.

30. El otorgante también puede necesitar obtener información actualizada acerca del alcance y valor de la garantía real invocada por su acreedor garantizado y copia de cualquier acuerdo de garantía escrito con arreglo al cual se invoca la garantía real. En algunos Estados, el otorgante tiene derecho a pedir esta información libre de cargo, si bien se imponen límites generalmente a la frecuencia que pueden hacerse estas peticiones a fin de desalentar las peticiones injustificadas o hechas con objeto de molestar.

31. Una notificación consignada en el fichero del registro contiene un mínimo de información sobre una garantía real, que tal vez ni siquiera exista en el momento de su inscripción y es posible que la cuantía de la obligación garantizada o los bienes gravados cambien de tanto en tanto (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párrs. 1 a 23, y proyecto de Guía sobre un registro, recomendación 21). Así pues, en ciertas circunstancias, el otorgante puede verse en la necesidad de solicitar información adicional sobre la garantía real. Aunque en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no se adopta una postura sobre esa cuestión, en algunos Estados el régimen de las operaciones garantizadas dispone que el otorgante tiene derecho a solicitar a la persona identificada en la notificación como acreedor garantizado que proporcione al autor de una consulta información adicional sobre la garantía real. Esa información consiste en: a) una lista de los bienes respecto de los cuales la persona identificada como acreedor garantizado afirma tener una garantía real; y b) la cuantía actual de la obligación amparada por la garantía real a que se refiere la inscripción, incluida la suma que ha de pagarse para liquidar esa obligación garantizada. Respecto de la posibilidad de que un tercero obtenga información del acreedor garantizado, se tiene en cuenta el hecho de que la inscripción no constituye ni demuestra la constitución de una garantía real, sino que sencillamente indica que puede existir una garantía real sobre un bien determinado. Pruebas no consignadas en el registro determinarán si se ha constituido o no la garantía real y los bienes que gravará esa garantía. Por consiguiente, los posibles compradores y acreedores garantizados, así como otros terceros con los que tenga negocios el otorgante quizás deseen una verificación independiente y directa por parte de la persona identificada en la notificación como acreedor garantizado en cuanto a que se afirma tener en el

momento una garantía real sobre un bien sobre el que puedan tener interés en virtud de un acuerdo de garantía existente con dicho otorgante. En algunos Estados, el otorgante tiene derecho a presentar una solicitud gratuitamente a intervalos de varios meses. Para responder a nuevas solicitudes de información, el acreedor garantizado podrá cobrar un derecho. Esto le evitará tener que responder a frecuentes solicitudes del otorgante que tal vez no se justifiquen o que tengan por objeto acosar a ese acreedor garantizado.

9. Función de la inscripción registral y sus consecuencias jurídicas

a) Constitución de una garantía, oponibilidad a terceros e inscripción registral

32. Como ya se dijo (véase, A/CN.9/WG.VI/WP.52, párrs. 30 y 36) la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la inscripción registral no sea un requisito necesario para la constitución de una garantía real (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 33). La garantía real surtirá efecto y pasará a ser ejercitable entre el otorgante y el acreedor garantizado, en cambio, tan pronto como se concierte un acuerdo de garantía (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 13 a 15). La inscripción registral es tan solo un requisito para hacer la garantía oponible a terceros. La única sanción para un acreedor garantizado que no inscriba la notificación de su garantía real es que esa garantía no podrá oponerse a terceros (a menos que haya optado por otro método de conseguir la oponibilidad a terceros).

b) Inscripción registral y ejecución

33. Algunos ordenamientos jurídicos exigen que los acreedores garantizados inscriban una notificación en el registro general de garantías reales de que han iniciado o se proponen iniciar una acción ejecutoria. La finalidad de este enfoque es permitir al registro notificar a terceros que hayan inscrito en el registro una garantía concurrente sobre los bienes gravados todo lo relativo a la ejecución pendiente. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no recomienda este enfoque. En su lugar, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el acreedor garantizado que procura obtener la ejecución tenga la obligación de consultar el registro y enviar las notificaciones necesarias a los terceros interesados (incluidos los reclamantes concurrentes) acerca de la acción ejecutoria particular que se propone ejercitar (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 151). Esta notificación brindará a los terceros interesados una oportunidad (si desean aprovecharla) de remediar el incumplimiento que dio lugar al procedimiento ejecutorio.

10. Coordinación con los registros especiales de bienes muebles

34. De existir algún registro especial que prevea la inscripción de una garantía real sobre bienes muebles que sea oponible a terceros (como en el caso de todo registro internacional creado en el marco del Convenio relativo a las garantías internacionales en elementos de equipo móvil y sus Protocolos), los regímenes legales modernos de las operaciones garantizadas deben regular las cuestiones que suscita la coordinación de las inscripciones registrales en los dos tipos de registro. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y el *Suplemento* examinan detenidamente la coordinación de los registros (véanse *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párrs. 75 a 82, cap. IV, párr. 117; y el *Suplemento*, párrs. 135 a 140).

35. Por ejemplo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* prevé que una garantía real sobre un bien sujeto a inscripción en un registro especial podrá hacerse oponible a terceros por inscripción en el registro general de las garantías reales o en dichos registro especial. La cuestión de la coordinación entre uno y otro registro la resuelve por medio de un régimen de prelación específico, y que da primacía a la inscripción de una notificación de la garantía en el registro especial pertinente sobre la notificación de una garantía sobre el mismo bien inscrita en el registro general de las garantías reales, con independencia del momento en que se realice la inscripción registral (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 43 y 77, apartado a)).

36. *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* examina también otros modos de coordinar registros, en particular, el reenvío automático de una copia de la información inscrita de un registro al otro y la apertura de una vía de acceso común a los registros. Esta solución planteará dificultades técnicas para el diseño del registro de las garantías reales si la inscripción en el registro especial ha de indexarse por bienes en vez de por otorgantes, como se hace en el registro general de las garantías reales (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párrs. 77 a 81; véase también A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrs. 30 a 35).

11. Coordinación con los registros de la propiedad inmobiliaria

37. En casi todos los países, sino en todos, existe un registro de la propiedad inmobiliaria. En la mayoría de esos países el registro general de las garantías reales se diferencia del registro de la propiedad debido a diferencias en cuanto a lo que se inscribe (es decir, un documento o una notificación), los requisitos de la descripción del bien gravado (es decir, si es específica o genérica), las modalidades de la indexación (es decir, si los índices se basan en los bienes o en los deudores; véase también A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrs. 30 a 35) y las consecuencias jurídicas de la inscripción registral.

38. Sin embargo, cierta coordinación de los dos tipos de registro puede resultar imprescindible con respecto a los bienes respecto de los cuales se hayan inscrito notificaciones de garantías en cualquiera de los dos registros. De este modo, un Estado que ponga en marcha un registro general de las garantías reales tendrá que proporcionar a los posibles acreedores garantizados y terceros financiadores orientación sobre el registro en el cual deberán inscribir las notificaciones relacionadas con las garantías reales sobre bienes muebles incorporados a bienes inmuebles. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que dichas inscripciones se efectúen en el registro general de las garantías reales o en el registro de la propiedad inmobiliaria (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 43). La elección entre los dos tipos de inscripción registral tiene consecuencias para la prelación. A este respecto, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el gravamen inscrito en el registro de la propiedad inmobiliaria tenga prelación sobre cualquier garantía real cuya notificación se haya inscrito solamente en el registro de garantías reales (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 87). La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* también recomienda que la garantía real sobre un bien mueble incorporado a un bien inmueble no sea oponible a un comprador (o tercero) que adquiera un derecho a menos que haya inscrito la notificación correspondiente a

la garantía real en el registro de la propiedad inmobiliaria con anticipación a la venta (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 88).

39. Cabe también señalar que la descripción de los bienes exigida para una notificación concerniente a un bien incorporado a un inmueble tal vez difiera según que la notificación vaya ser inscrita en un registro general de las garantías reales o en un registro de la propiedad de la propiedad. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que todo bien incorporado a un inmueble, como cualquier otro bien gravado, sea descrito en términos que permitan su debida identificación cuando se inscriba una notificación en el registro general de las garantías reales (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, apartado b)). Por eso, para inscribir una notificación en el registro general de las garantías reales bastará con dar una descripción del bien corporal que se haya incorporado o se vaya a incorporar al inmueble, mientras que para inscribirlo en un registro de la propiedad hará falta que el bien inmueble al que esté incorporado o al que vaya a ser incorporado sea descrito en los términos exigibles por el régimen legal de la propiedad inmobiliaria. Esta descripción habrá de permitir la indización de la notificación en el registro de la propiedad.

I. Creación y funciones del registro de garantías reales

A. Observaciones generales

1. Creación del registro de garantías reales

40. Como ya se dijo, el capítulo IV de la *Guía sobre las operaciones garantizadas*, contiene un comentario y recomendaciones sobre muchos aspectos relacionados con la creación de un registro de garantías reales y los procesos de inscripción registral y de búsqueda o consulta. Las recomendaciones contenidas en el capítulo IV abarca tanto cuestiones jurídicas, que normalmente se tratan en el régimen principal de garantías reales, como las cuestiones de diseños y funcionamiento que, por lo general, se abordan en cuerpos suplementarios de reglas administrativas, que, el proyecto de guía sobre el registro se denomina “reglamento”. Este enfoque hace posible que las reglas relacionadas con las funciones de inscripción registral y de consulta del registro se puedan revisar con mayor facilidad de tanto en tanto para dar cabida a los progresos tecnológicos y demás. Como ya se explicó (véase, A/WG.VI/WP.52, párrs. 35 a 40), en la *Guía sobre las operaciones garantizadas* se aclara que el propósito del registro de garantías reales consiste en proporcionar: a) un método que permita hacer que una garantía real sea oponible a terceros; b) un punto de referencia eficiente para determinar el orden de prelación de las garantías reales respecto de las cuales se ha inscrito una notificación; y c) una fuente objetiva de información para terceros (véase la *Guía sobre las operaciones garantizadas*, cap. IV, finalidad). En la mayoría de los casos, las primeras disposiciones del reglamento prevén el establecimiento del registro y reiteran brevemente que, en consonancia con su finalidad según se expone en la Ley, la finalidad del registro consiste en recibir, almacenar y facilitar al público información relativa a las garantías reales sobre bienes muebles (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 1).

2. Nombramiento del director del registro

41. El nombramiento de la persona encargada de supervisar y administrar el funcionamiento del registro (el “director del registro” es otra de las cuestiones que suelen tratarse en las disposiciones iniciales del reglamento. Por lo general, el reglamento indica, sea directamente o por remisión al régimen pertinente, la autoridad facultada para designar al director del registro, determinar sus funciones y, en general, supervisar al director del registro en el ejercicio de esas funciones. A fin de asegurar la flexibilidad en la administración del registro, conviene aclarar que por secretario de registro se entenderá una sola persona o un grupo de personas designadas y supervisadas por el director del registro para desempeñar sus funciones (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 2).

3. Funciones del registro

42. Entre las disposiciones iniciales del reglamento puede figurar también una disposición en la cual se enumeren las diversas funciones del registro que se tratan detenidamente más adelante en el reglamento con remisiones a la disposición pertinente del reglamento en que se trata de esas funciones. Este es el enfoque recomendado en el proyecto de guía sobre el registro (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 3). La ventaja de este enfoque reside en la claridad y la transparencia en cuanto al carácter y alcance de las cuestiones tratadas detenidamente en disposiciones posteriores del reglamento. La posible desventaja es que la lista pueda no ser exhaustiva o que se interprete en el sentido de que impone limitaciones no buscadas respecto de las disposiciones detalladas del reglamento a las que se refiere la remisión. Por consiguiente, la aplicación de este enfoque exige especial cuidado de evitar omisiones y contradicciones.

4. Otras consideraciones relativas a la creación del registro

43. Es de importancia crítica que el personal técnico encargado del diseño y la puesta en marcha del registro esté plenamente informado de los objetivos jurídicos y prácticos que persigue, así como de las necesidades prácticas del personal del registro y de sus posibles usuarios. Por consiguiente, es preciso establecer, desde el principio mismo del proceso de diseño y puesta en marcha, un equipo que reúna los conocimientos técnicos, jurídicos y administrativos necesarios y que comprenda las necesidades del usuario.

44. Será necesario también, desde las etapas iniciales del diseño y puesta en marcha del registro, determinar si será administrado internamente por una entidad estatal o en colaboración con una firma del sector privada de probada experiencia técnica y con responsabilidad financiera demostrada. Aunque el funcionamiento cotidiano del registro podría delegarse a una entidad privada, el Estado promulgante debería conservar siempre la responsabilidad de asegurar que el registro funcione conforme al marco jurídico aplicable (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 47, y recomendación 55, apartado a)). En consecuencia, para fomentar la confianza pública en el registro y prevenir la comercialización y el uso fraudulento de la información consignada en el fichero del registro, el Estado promulgante debería retener la propiedad del fichero del registro y, en caso necesario, de su infraestructura.

45. El equipo encargado del diseño deberá planificar la capacidad del almacenamiento del fichero del registro. La evaluación dependerá en parte de si el registro tendrá por fin abarcar las operaciones financieras garantizadas no solo de los consumidores sino también del sector comercial. En tal caso, cabe prever un volumen mucho mayor de inscripciones, por lo que se debería aumentar la capacidad de almacenamiento. En la planificación de la capacidad se deberá tener en cuenta la posibilidad de agregar aplicaciones y características al sistema. Por ejemplo, los diseñadores deberán tener en cuenta la necesidad de ampliar en el futuro la base de datos del registro para permitir la inscripción de sentencias o de garantías reales no consensuales, o la adición de vínculos con otras bases de datos públicas, como las del registro público de sociedades u otros registros de bienes muebles o inmuebles. La planificación de la capacidad dependerá también de si la información inscrita se almacena en una base de datos informatizada o se consigna en documentos en papel. La necesidad de proporcionar suficiente capacidad de almacenamiento u otros registros de bienes muebles o inmuebles. La planificación de la capacidad dependerá también de si la información inscrita se almacena en una base de datos informatizada o se consigna en documentos en papel. La necesidad de proporcionar suficiente capacidad de almacenamiento constituye un problema mucho menos importante si el fichero es electrónico, gracias a los recientes avances tecnológicos, que han reducido considerablemente el costo del almacenamiento (la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el registro sea electrónico “en lo posible”; véase la recomendación 54, apartado j), y los párrafos 48 a 55 *infra*).

5. Condiciones de uso del registro

46. Como ya se dijo, las cuestiones relacionadas con el registro se tratan normalmente en el régimen de garantías reales y el reglamento del registro. También pueden tratarse en las “condiciones y requisitos de uso” del registro. Las condiciones y los requisitos del uso del registro son requisitos y condiciones del contrato que conciertan las personas que inscriben, modifican o suprimen notificaciones, por un lado, y el contrato que rige las condiciones de acceso a los autores de consultas, por el otro. Por ejemplo, las condiciones de uso del registro pueden ofrecer la oportunidad, a un usuario frecuente del registro, de abrir una cuenta. Esto ofrecería beneficios prácticos como, por ejemplo, el rápido acceso al registro y un mecanismo simplificado para el pago de derechos. Además, al establecerse las condiciones de uso del registro deberían prestarse atención a los problemas de la seguridad y confidencialidad de la información y de los datos sobre los usuarios (como, por ejemplo, el nombre del usuario y la contraseña, u otras técnicas modernas de seguridad).

47. Algunos sistemas de registro ponen a disposición de los usuarios que así lo solicitan servicios adicionales. Entre ellos pueden figurar, por ejemplo, los siguientes: a) revisión de la consulta, que proporciona información sobre la forma en que se realizó la búsqueda con la lista de correspondencia exactas o similares e indicación de cuáles fueron las correspondencias similares que se buscaron en una consulta subsiguiente; b) averiguación sobre la operación, que permite al usuarios localizar por el nombre o la cuenta información sobre las operaciones realizadas durante un período determinado; c) búsquedas de acreedores garantizados, lo cual permite al autor de la consulta buscar recurriendo al identificador del acreedor garantizado; d) búsqueda avanzada, que permite recuperar y facilitar todas las

inscripciones activas e inactivas que constan en las bases según un criterio de búsqueda específico; e) comprobante reimpreso de la verificación, que proporciona reimpresos de una verificación relacionada con operaciones concretas; y f) informes estadísticos.

6. Registro electrónico o de documentos en papel

48. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que, de ser posible, el fichero del registro sea electrónico en el sentido de que la información contenida en las notificaciones habrá de almacenarse en forma electrónica en una base de datos informática (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 38 a 41 y 43 y recomendación 54, apartados j) i)). Un fichero de registro electrónico es la forma más eficiente y práctica de permitir a los Estados promulgantes y que lleven a la práctica la recomendación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* de que el fichero del registro sea centralizado y reúna todas las inscripciones registrales realizadas con arreglo al régimen de las garantías reales del Estado promulgante (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 21 a 24, y recomendación 54, apartado e)).

49. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda también que, en lo posible, el registro sea electrónico en el sentido de que permita la inscripción electrónica directa de las notificaciones y las búsquedas por los usuarios a través de Internet o, directamente, por sistemas de redes, en contraposición a la presentación de notificaciones y consultas en formularios de papel (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 23 a 26 y 43 y recomendación 54, apartado j) ii)). Este enfoque constituye el medio más eficaz de llevar a la práctica la recomendación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* de que el sistema debería estar diseñado de modo que reduzca al mínimo el riesgo de error humano (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, recomendación 54, apartado j) iii) a iv)), puesto que se elimina así la necesidad de que el personal del registro ingrese la información contenida en el formulario impreso con la solicitud de búsqueda en el fichero del registro y el riesgo de error que entraña la tarea de transcripción.

50. Las inscripciones y búsquedas electrónicas directas contribuyen también a la agilización del proceso de inscripción y búsqueda. Cuando la información se presenta al registro en documentos en papel, los autores de la inscripción deben esperar hasta que el personal del registro haya incorporado esa información al fichero del registro antes de que pueda consultarse por terceros y la inscripción empiece a surtir efecto legal. Las consultas enviadas por correo, fax o teléfono también causan demoras, porque el interesado tiene que esperar a que un empleado del registro haga la consulta en su nombre y le comunique los resultados.

51. Además de eliminar estas demoras y de reducir el riesgo de error humano, un sistema de registro en que los autores de inscripciones y búsquedas tengan la posibilidad de incorporar directamente o por vía electrónica la información al fichero del registro tiene las siguientes ventajas:

- a) Una reducción muy considerable del personal y de los gastos diarios del funcionamiento del registro;
- b) Una reducción de las oportunidades de conducta fraudulenta o corrupta del personal del registro;

c) Una reducción correspondiente de la posible responsabilidad del registro frente a los usuarios que pudieran sufrir pérdidas debido a que el personal del registro no hubiera anotado la información consignada de la inscripción o los criterios de búsqueda o lo hubiera hecho de forma incorrecta; y

d) Acceso del usuario a los servicios de inscripción y de consulta fuera de los horarios normales de trabajo.

52. Si se adopta ese enfoque, el registro debería diseñarse de modo que permitiera a los usuarios hacer inscripciones registrales y realizar consultas desde cualquier computadora privada, o desde las computadoras instaladas en las sucursales del registro u otras oficinas. Además, debido al costo reducido del acceso electrónico directo, las condiciones de accesos a los servicios del registro deberían permitir que los proveedores privados de servicios que actúen como terceros presten servicios de registro a las partes interesadas.

53. Si el fichero del registro está informatizado, las especificaciones del equipo y los programas informáticos deberán ser estrictas y emplear mecanismos de seguridad que reduzcan al mínimo el riesgo de deterioro de los datos, los errores técnicos y el fallo de los mecanismos de seguridad. Aún en los registros de documentos en papel, deberían de adoptarse medidas para garantizar la seguridad e integridad del fichero del registro si bien es cierto que esto mismo se logra de manera más eficiente y fácil si el fichero del registro es electrónico. Además de los programas de control de la base de datos, será necesario elaborar programas informáticos para gestionar las comunicaciones de los usuarios, las cuentas de los usuarios, los pagos de derechos y la contabilidad financiera, las comunicaciones entre computadoras y la reunión de datos estadísticos.

54. Será necesario asimismo evaluar las necesidades de equipo de programas y decidir que conviene más: elaborar internamente los programas de informática encomendando la tarea al equipo encargado de la ejecución o adquirirlos a proveedores privados. Para tomar una decisión al respecto, el equipo deberá investigar si existen productos comerciales que puedan adaptarse fácilmente a las necesidades del Estado promulgante. Es importante que el creador o proveedor de los programas informáticos tenga conocimientos de las especificaciones del equipo que ha de ser suministrado por un tercero, y viceversa.

55. También deberá tenerse en cuenta si el registro ha de diseñarse para proporcionar una interfaz electrónica con otras bases de datos estatales. Por ejemplo, en algunos Estados, los autores de una inscripción pueden consultar el registro comercial o de las empresas mientras efectúan una inscripción para verificar e ingresar automáticamente la información sobre el identificador del otorgante o del acreedor garantizado (para un examen de la cuestión de la correspondencia electrónica de los nombres, véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.3, párr. 10).

B. Recomendaciones 1 a 3

[Nota al Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las recomendaciones 1 a 3, tal como figuran en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.5. El Grupo de Trabajo quizás también desee observar que, por razones de economía, las recomendaciones 1 a 3 no se han incluido en el presente documento en esta etapa pero se incluirán en el texto definitivo.]

II. Acceso a los servicios del registro

A. Observaciones generales

1. Acceso del público

56. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que cualquier persona pueda inscribir una notificación de una garantía real (de existencia potencial) o efectuar una búsqueda en el fichero del registro accesible al público (no los archivos; véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 25 a 30, y recomendación 54, apartados f) y g)). Este enfoque está en consonancia con uno de los objetivos clave de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* que consiste en acentuar el grado de certeza y transparencia previendo la inscripción registral de una notificación de una garantía real en el registro general de garantías reales (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 25, y recomendación 1, apartado f)). Dada la importancia del principio del acceso del público a los servicios del registro, debería reiterarse en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 5).

57. El acceso del público se facilita en la medida en que los usuarios con acceso a una computadora y a Internet están en condiciones de remitir notificaciones y realizar búsquedas electrónicamente, sin necesidad de la asistencia ni intervención del personal del registro. Como ya se vio (véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1, párrs. 48 a 55), la inscripción registral de formularios de papel entraña mayores costos, demoras y posibles errores y responsabilidad del registro. En todo caso, aun cuando el sistema del registro permita o exija el uso de formularios impresos, el fichero del registro debería estar informatizado y ser accesible a distancia a través de Internet. Además, el acceso del público a los servicios de inscripción del registro se ve facilitado en la medida en que el registro no impone condiciones de acceso innecesarias a los autores de inscripciones (véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrs. 1 y 2), ni exige la verificación de la identidad del autor de una inscripción, pruebas de la existencia de autorización para efectuar esa inscripción ni somete a examen el contenido de la notificación (véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrs. 3 a 7).

58. Invocando razones de privacidad, algunos Estados exigen que los autores de búsquedas indiquen que tienen motivos justificables para realizar una búsqueda. A fin de facilitar el acceso a los servicios de búsqueda del registro, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el registro no exija al autor de una consulta que dé las razones que la justifican (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 54, apartado g)). La privacidad del otorgante se encuentra suficientemente amparada por un régimen que exige solo una medida

limitada de información sobre el acuerdo de garantía pertinente que de ha de incluirse en una notificación. La privacidad del acreedor garantizado está suficientemente protegida por el registro al no permitir búsquedas de terceros basadas en el identificador del acreedor garantizado y el permitir al acreedor garantizado que ingrese el nombre y la dirección de un representante como acreedor garantizado en la notificación, así como por el número limitado de datos sobre la operación exigidos. Además, el pedir a los autores de consultas que den las razones que justifican la consulta socavaría la eficiencia y funcionalidad del proceso de búsqueda, puesto que el registro tendría entonces que examinar las razones dadas y determinar si son suficientes para justificar o no la búsqueda. Además, según qué razones se considerasen aceptables, el acceso abierto a la información del registro como parte de un mercado eficiente y transparente podría verse entorpecido, por lo menos en la medida en que ciertas partes que tratan con el otorgante podrían no tener la información que disponen otras partes.

2. Días y horas de funcionamiento del registro

59. El enfoque de los días y horas de funcionamiento del registro que se recomienda en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* depende de la medida en que el registro haya sido concebido para permitir la inscripción y la consulta electrónica directa por los usuarios o si hace falta presentarse en persona a la oficina física del registro. En el primer caso, el registro debería ser accesible a toda hora, salvo durante los propios lapsos necesarios para los servicios de mantenimiento; en el segundo caso, debería estar abierto al público con un horario compatible con las necesidades de los usuarios del registro potenciales (véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 42 y recomendación 54, apartado I)). En vista de la importancia de esta cuestión para los usuarios, debería tratarse en el reglamento o en las directrices administrativas publicadas por el registro (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 5).

60. En los casos en que el registro preste servicios mediante una oficina física, los días y horas de funcionamiento mínimos deberían ser los días hábiles y horarios de oficina normales en el Estado promulgante. En la medida en que el registro exija o permita la inscripción de notificaciones en formularios impresos o la presentación de formularios de búsquedas impresos, la hora de recepción de los formularios impresos, y la hora en que la información se ingresará en el fichero del registro y se pondrá a disposición de los autores de consultas, el mismo día hábil, puede fijarse independientemente del horario de oficina. Por ejemplo, en el reglamento o las directrices administrativas del registro podría establecerse que, si bien la oficina del registro está abierta de 9.00 horas a 17.00 horas, todos los formularios deberán recibirse antes de determinada hora (por ejemplo, 16.30) de modo que el personal del registro tenga tiempo suficiente para consignar la información contenida en las notificaciones en el fichero del registro o para realizar una búsqueda. Otra posibilidad sería que la oficina aceptara notificaciones impresas durante todas las horas de oficina pero que fijara una hora de “cierre”, tras la cual la información contenida en las notificaciones recibidas no se podrá ingresar en el fichero del registro hasta el siguiente día hábil.

61. El reglamento del registro o las directrices administrativas podrían enumerar también de manera exhaustiva o indicativa las circunstancias en que el acceso a los servicios del registro podría quedar interrumpido transitoriamente. Una lista

exhaustiva daría mayor certeza pero existe el riesgo de que no cubra todas las circunstancias posibles. Una lista indicativa proporcionaría mayor flexibilidad pero menor certeza. Entre las circunstancias que podrían justificar una suspensión de los servicios del registro podrían incluir cualquier acontecimiento que haga imposible o poco práctico proporcionar a los usuarios acceso a los servicios del registro (por ejemplo, en los casos en que el registro proporcione a los usuarios acceso electrónico directo a sus servicios, razones de fuerza mayor, de vidas, por ejemplo, incendio, inundación, terremoto, guerra o fallos de funcionamiento de Internet o del acceso a redes).

(A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2) (Original: inglés)

**Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre
la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de
Trabajo sobre Garantías Reales en su 22º período de sesiones**

[Original: inglés]

ADICIÓN

Índice

	<i>Párrafos</i>
II. Acceso a los servicios del registro (<i>continuación</i>)	1-10
A. Observaciones generales (<i>continuación</i>)	1-10
3. Acceso a los servicios de inscripción y de consulta	1-2
4. No son necesarias la verificación de la identidad, las pruebas de autorización ni el examen del contenido de la notificación	3-7
5. Rechazo de una inscripción registral o de una consulta	8-10
B. Recomendaciones 4 a 9	
III. Inscripción registral	11-58
A. Observaciones generales	11-58
1. Fecha en que surte efecto la notificación inscrita en el registro	11-16
2. Plazo de vigencia de la notificación inscrita en el registro	17-24
3. Momento en que puede inscribirse una notificación	25-27
4. Suficiencia de una notificación única	28-29
5. Indización u otra forma de organizar la información del fichero del registro	30-35
6. Integridad del fichero del registro	36-40
7. Responsabilidad del registro	41
8. Copia de la notificación inscrita en el registro	42-46
9. Modificación de la información consignada en una notificación inscrita en el registro	47-50
10. Retiro de la información del fichero del registro accesible al público y archivo de esa información	51-53
11. Idioma de la notificación	54-58
B. Recomendaciones 10 a 20	

II. Acceso a los servicios del registro (*continuación*)

A. Observaciones generales (*continuación*)

3. Acceso a los servicios de inscripción y de consulta

1. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que el registro esté obligado a aceptar una notificación si: a) se presenta en el medio de comunicación autorizado (es decir, en el formulario impreso o electrónico prescrito, según el caso); b) va acompañada del pago del derecho de inscripción autorizado, si procede; y c) proporciona el identificador del otorgante así como la demás información que debe consignarse en la notificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 54, apartado c)). Además, a modo de salvaguardia contra el riesgo de inscripciones no autorizadas, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el registro esté obligado a pedir y mantener una constancia de la identidad del solicitante de la inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 55, apartado b)).

2. Para aplicar estas recomendaciones, el reglamento debería disponer que toda persona tenga derecho a acceder a los servicios de inscripción del registro, siempre que: a) utilice el formulario prescrito para la notificación; b) informe sobre su identidad de la manera prescrita por el registro; y c) haya pagado, o dispuesto lo necesario para pagar, cualquier derecho de inscripción (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 6). Para que una persona pueda tener acceso a los servicios de consulta del registro, el reglamento debería disponer que basten las siguientes condiciones: a) emplear el formulario de búsqueda prescrito (incluido el requisito de anotar los criterios de la búsqueda en los espacios pertinentes del formulario de búsqueda); b) haber pagado o dispuesto lo necesario para pagar los derechos de consulta prescritos, si procede (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 7)). No es necesario que el registro pida y mantenga constancia de la identidad del autor de la consulta puesto que, a diferencia de la inscripción no autorizada, una consulta del registro no crea ningún riesgo de perjuicio para un otorgante consignado en una notificación (en cuanto a las inquietudes suscitadas por la privacidad, véase el párr. 3 *infra*). Cabe observar que la consulta se relaciona con el fichero del registro, que es accesible al público mediante la interfaz, que constituye simplemente un portal de entrada a la base de datos que contiene los datos, y no a la información archivada, es decir, la información consignada en las notificaciones inscritas y retiradas, una vez vencido el plazo de vigencia o una vez inscrita una notificación de cancelación, del fichero accesible al público (véanse los párrs. 51 a 53 *infra* y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 18).

4. No son necesarias la verificación de la identidad, las pruebas de autorización ni el examen del contenido de la notificación

3. Como ya se dijo (véanse los párrs. 1 y 2 *supra*), la *Guía de las Operaciones Garantizadas* recomienda que el registro esté obligado a pedir y mantener una constancia de la identidad del solicitante de la inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrafo 48, recomendación 55, apartado b)). A fin de facilitar el proceso de la inscripción, los requisitos de la identificación deberían reducirse al mínimo (por ejemplo, presentación de un documento de

identidad expedido por el Estado, licencia para conducir o pasaporte) y estar integrados en el trámite de acceso o pago. Por ejemplo, los usuarios frecuentes como las instituciones financieras, los vendedores de automóviles, los abogados y otros intermediarios que actúen como autores de inscripciones y consultas, deberían tener la opción de establecer una cuenta de usuario en el registro que permitiera el cobro automático de cuotas y les proporcionara claves de acceso seguras y especiales para consignar información y realizar consultas.

4. Además, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la inscripción de una notificación no surta efecto a menos que el otorgante la haya autorizado por escrito. Sin embargo, la autorización puede hacerse antes o después de la inscripción y un acuerdo de garantía por escrito será suficiente para constituir la autorización (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrafo 106 y recomendación 71). Además, a fin de no recargar el proceso de inscripción con formalidades innecesarias que puedan ocasionar demoras y gastos, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el registro no esté obligado a verificar la identidad del solicitante de la inscripción o pedir pruebas de la existencia de autorización para inscribir la notificación, ni tampoco investigar más a fondo el contenido de la notificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 54, apartado d)). En vista de la importancia de estas recomendaciones, deberían recogerse en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 8). Por consiguiente, la función del registro es cumplir las tareas enunciadas en las recomendaciones que se acaban de mencionar. La cuestión de si el autor de una inscripción estaba o no facultado para inscribir una notificación excede los límites del mandato del registro. Lo mismo vale para las modificaciones y cancelaciones, que deben estar autorizadas por el acreedor garantizado, pues pueden afectar a sus derechos. A este respecto, cabe observar que, salvo contadas excepciones, todas las modificaciones pueden afectar a los derechos del acreedor garantizado y requerir, por tanto, su autorización. Por lo general, solo dos modificaciones, la adición de un otorgante y de bienes gravados, requieren únicamente la autorización del otorgante.

5. En los casos en que el sistema ha sido concebido de manera que sea posible inscribir electrónicamente las notificaciones de manera directa, hay métodos muy eficaces para impedir que se hagan inscripciones, modificaciones o cancelaciones fraudulentas. Por ejemplo, un acreedor garantizado podría pedir que le asignasen un número de identificación de usuario para emplearlo al efectuar una inscripción. No sería posible hacer ninguna modificación ni cancelación de una notificación inscrita a menos que se utilizara ese número. Si el acreedor garantizado no mantuviese la confidencialidad de ese número, carecería de fundamento para quejarse de cancelaciones o modificaciones no autorizadas. Sin embargo, si el acreedor garantizado obrase con discreción, sería prácticamente imposible que la inscripción se modificara en manera alguna sin su participación.

6. Sin embargo, cuando el sistema de registro ha sido diseñado de manera que permite o exige que las notificaciones sean inscritas en documentos en papel, es muy poco lo que el acreedor garantizado puede hacer para impedir que se inscriba una modificación o cancelación no autorizada de manera fraudulenta. En todo caso, a fin de proteger al acreedor garantizado, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que se envíe al solicitante de la inscripción copia de todas las modificaciones y cancelaciones efectuadas a una notificación inscrita, es decir,

al acreedor garantizado identificado en la notificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 55, apartado d)). Los sistemas de registro suelen incluir mecanismos de seguridad intrínseca que proporcionan a los acreedores garantizados la oportunidad de restablecer o corregir una notificación inscrita que haya sido enmendada o cancelada por inadvertencia o sin la debida autorización dentro de un breve plazo después de efectuada la inscripción de la notificación de modificación o cancelación. En los Estados que han adoptado este enfoque, el restablecimiento efectuado dentro del plazo especificado es oponible a terceros distintos de los que adquieren un derecho sobre el bien gravado durante el plazo que sigue a la inscripción de la notificación de modificación o cancelación y antes de la inscripción del restablecimiento o corrección. En otros Estados, todas las inscripciones se mantienen en el fichero del registro accesible al público durante cierto plazo, en tanto que la cuestión de si la cancelación tiene o no tiene validez se determina fuera del sistema del registro.

7. Una vez que el solicitante de la inscripción obtiene acceso a los servicios del registro y cumplimenta todos los espacios requeridos de la notificación, el registro no tiene derecho a rechazar la notificación. Esto no significa necesariamente que la notificación inscrita haya de surtir efecto y la garantía real a la que se refiere la notificación sea oponible a terceros. Este último resultado depende del cumplimiento de los requisitos para la constitución de una garantía real en el régimen de operaciones garantizadas, que no es de competencia del fichero del registro (la concertación de un acuerdo de garantía válido, la existencia de derechos del otorgante sobre los bienes gravados designados y la existencia de una obligación pendiente adeudada al acreedor garantizado o su compromiso a extender créditos). Además, para que la notificación inscrita alcance su objetivo, el solicitante de la inscripción deberá también satisfacer los requisitos del reglamento y del régimen de operaciones garantizadas para inscribir una notificación (es decir, que toda la información que debe consignarse en la notificación se haya ingresado en los espacios apropiados). Todas estas cuestiones son de responsabilidad del solicitante de la inscripción. Si el registro tuviera que examinar la notificación y confirmar que está completa, además de verificar su exactitud y suficiencia jurídica, el resultado sería una multiplicación de las demoras, gastos y posibles errores, lo cual sería contrario al tipo de registro eficiente que se prevé en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

5. Rechazo de una inscripción registral o de una consulta

8. Como se acaba de explicar (véase el párrafo 7 *supra*), el hecho de que el autor de una inscripción o consulta obtenga acceso a los servicios del registro no significa necesariamente que la inscripción sea automáticamente aceptada o que se obtenga respuesta a la consulta. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que la notificación contenga cierta información, como el identificador y la dirección del otorgante y del acreedor garantizado, una descripción de los bienes gravados y, si el régimen de las operaciones garantizadas así lo exige, una declaración sobre el plazo de vigencia de la notificación inscrita y el importe máximo que pueda exigirse con arreglo a la garantía (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrs. 92 a 97, y recomendación 57).

9. En vista de la importancia de estos requisitos, el reglamento debería prever que se permita al registro rechazar la inscripción de una notificación solo si no contiene de manera legible la información necesaria en los espacios designados (para la información que ha de consignarse en una notificación inicial, de modificación o de cancelación, véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.3, párrs. 1 y 2, A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párr. 4, y el proyecto de guía sobre el registro, recomendaciones 21, 28 y 30). Además, debería preverse en el reglamento que el registro estará facultado para rechazar una consulta solo si no se proporciona un criterio de búsqueda de manera legible en el espacio reservado para ese fin. Más aún, en el reglamento debería precisarse que el registro está obligado a fundamentar el rechazo de una inscripción registral o una consulta inmediatamente o tan pronto como sea posible (en el caso de otros registros) (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 9).

10. Cabe observar que el registro podrá rechazar las solicitudes de inscripción y de consulta presentadas en formularios impresos que no se ajusten a los requisitos previstos, en tanto que un sistema de registro que permita hacer electrónicamente las inscripciones registrales o las solicitudes de búsqueda estará diseñado de modo que rechace automáticamente cualquier solicitud que no reúna los requisitos. Además, si bien en el caso de una notificación presentada en un formulario impreso las razones del rechazo se comunicarán tan pronto como sea posible, en el caso de una inscripción electrónica, el sistema debería estar diseñado de modo que el rechazo quede inmediatamente visualizado en el monitor.

B. Recomendaciones 4 a 9

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las recomendaciones 4 a 9 tal como se reproducen en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.5. El Grupo de Trabajo quizá desee observar también que, por razones de economía, las recomendaciones no se han incluido en el presente documento en esta etapa pero se incluirán en el texto definitivo.]

III. Inscripción registral

A. Observaciones generales

1. Fecha en que surte efecto la notificación inscrita en el registro

11. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la inscripción registral de una notificación o modificación sea válida a partir del momento en que la información consignada en la notificación o modificación se inscriba en el fichero del registro de manera que pueda ser consultada por los interesados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrs. 102 a 105, y recomendación 70).

12. En vista de la importancia de la fecha en que surte efecto la inscripción registral para determinar la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real, el reglamento podría repetir esta recomendación (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 10, apartado a)). En particular, el reglamento debería disponer que: a) la fecha en que surte efecto la inscripción (es decir, la fecha

y hora en que la notificación puede ser objeto de búsquedas) debería constar en el fichero del registro; y b) el reglamento debería prever la asignación de un número de inscripción único a la notificación inicial de manera que todas las notificaciones de modificación subsiguientes o notificaciones de desgravación queden asociadas con la notificación inicial (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 10, apartado b); véase asimismo A/AC.9/WG.VI/WP.52, sección B, terminología e interpretación, “número de inscripción”). En el caso improbable pero posible de que distintas notificaciones inscritas por acreedores garantizados concurrentes queden abiertas a la consulta en la misma fecha y hora y, por consiguiente, se les asigne la misma fecha y hora de inscripción registral, el régimen de operaciones garantizadas podría disponer que, si hubiera una ligera diferencia cronológica, por leve que fuera, en la recepción de las notificaciones, debería establecerse la prelación según la sucesión exacta en que fueron recibidas las notificaciones o, si fueron recibidas exactamente al mismo tiempo, tendrán las dos, sencillamente, el mismo orden de prelación.

13. En los casos en que la información contenida en las notificaciones se ingresa en un fichero de registro informatizado, el software del registro debería estar diseñado de manera que se asegure que la información quede abierta a las consultas o búsquedas por el público de inmediato o casi inmediatamente después de su ingreso. Con los adelantos de la tecnología moderna, esto no debería ser ningún problema. Por consiguiente, se eliminará de este modo toda demora entre el ingreso en el fichero de la información consignada en una notificación y el momento en que la información pueda ser consultada por el público. Esto es importante porque cualquier demora crearía un riesgo de prelación para los acreedores garantizados puesto que sus garantías quedarían subordinadas a las garantías de terceros adquiridas sobre los bienes gravados antes de que surta efecto la inscripción en el registro y pueda ser objeto de consultas por el público. En los sistemas que permiten la inscripción electrónica directa de una notificación, los autores de la inscripción tienen control sobre el momento y la eficiencia con que surten efecto las inscripciones registrales. Sin embargo, en la medida en que medie un lapso (en particular, en los sistemas de registro que permiten o exigen la presentación de las notificaciones en formularios impresos), para poder adelantar fondos con confianza, los autores de inscripciones deberían hacer una “inscripción anticipada” (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrs. 98 a 101 y recomendación 67). Además, los autores de la inscripción deberían cerciorarse de que: a) la información consignada en la notificación haya sido ingresada en el fichero del registro por el personal del registro y pueda consultarse y b) no se hayan inscrito en el registro notificaciones de garantías concurrentes en el lapso transcurrido entre la presentación de la notificación en un formulario impreso y el momento en que la información quedó abierta a las consultas.

14. A fin de abordar el problema creado por el lapso transcurrido después de la inscripción de notificaciones presentadas en formularios impresos, el reglamento podría disponer que el registro estuviera obligado a ingresar en el fichero del registro la información consignada en las notificaciones en el orden en que las notificaciones consignadas en formularios impresos fueron recibidas por el registro (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 10, apartado c)). Este enfoque aseguraría que una notificación recibida el primero de enero a las 08.00 horas quedaría registrada en el fichero y abierta a las consultas por el público de modo

que empezara a surtir efecto jurídico antes que otra notificación recibida por el registro en la misma fecha a las 08.01 horas.

15. Cabe observar que esta recomendación no habría de proteger necesariamente al acreedor garantizado que fuera el primero en presentar una notificación en un formulario impreso ante un registro híbrido que permita la presentación de notificaciones tanto en formularios impresos como en forma electrónica. Así, por ejemplo, en el caso de que se reciba una notificación en un formulario impreso a las 08.00 horas y el personal del registro la ingrese en el fichero del registro de modo que quede abierta a las consultas a las 08.30, pero otro acreedor garantizado concurrente ingrese electrónicamente una notificación a las 08.05 que quede abierta a las consultas a las 08.10, este último tendrá prelación puesto que su notificación fue la primera en quedar abierta a las consultas y, por tanto, la primera en quedar registrada. En los sistemas que adoptan este enfoque híbrido, los autores de inscripciones que opten por el uso de formularios impresos deberían ser informados acerca de este riesgo.

16. En algunos ordenamientos jurídicos, para resolver el problema del tiempo transcurrido después de la inscripción, se asigna “una fecha en que surte efecto” a los resultados de la consulta en la que se indica que los resultados de la consulta tienen por objeto revelar únicamente el estado de las inscripciones en el fichero del registro en la fecha y hora en que surten efecto (por ejemplo, un día antes de la consulta) y no en el momento real de la consulta. Si bien este enfoque puede no resolver el problema, proporciona una advertencia a un posible acreedor garantizado que, después de inscribir su garantía real, tendría que hacer una segunda consulta para asegurarse de que no se hayan inscrito otras notificaciones y poder adelantar los fondos con confianza. Los posibles compradores y otros terceros necesitarían, de igual modo, realizar una consulta posterior antes de desprenderse de bienes o actuar de cualquier otro modo que suponga fiarse del fichero del registro.

2. Plazo de vigencia de la notificación inscrita en el registro

17. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que los Estados promulgantes adopten uno de los dos enfoques siguientes del plazo de vigencia (o duración de la eficacia) de una notificación inscrita en el registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrs. 87 a 91, y recomendación 69).

18. Con arreglo a la opción A, todas las notificaciones inscritas en el registro tienen un plazo de vigencia uniforme fijado por ley. De ello se desprende que, en los casos en que la operación garantizada a la que se refiere la notificación inscrita en el registro tiene una duración más larga, el acreedor garantizado deberá asegurarse de que el período de vigencia sea renovado antes del vencimiento del plazo legal. Este enfoque proporciona certeza en cuanto al período de vigencia de una notificación inscrita en el registro, pero limita la flexibilidad del solicitante de la inscripción para ajustar el plazo de vigencia de la notificación inscrita a la duración probable de la operación financiera garantizada. Con arreglo a la opción B, el solicitante de la inscripción está facultado para elegir por sí mismo el período de vigencia deseado con la posibilidad de renovar la notificación por un plazo adicional de su elección inscribiendo una notificación de modificación. En tal caso, la indicación del plazo en la notificación pasaría a ser un componente obligatorio de la notificación y, sin él, la notificación sería rechazada. En los ordenamientos jurídicos que adoptan el segundo enfoque, puede resultar conveniente basar los derechos de inscripción en

una tarifa de escala móvil que esté en función de la duración elegida por el solicitante de la inscripción a fin de disuadir de la elección de plazos excesivamente largos que no guarden proporción con la duración de los acuerdos de garantía correspondientes (con un margen de tiempo adicional para tener en cuenta las demoras en el pago de una obligación garantizada).

19. En vista de la importancia de esta cuestión, debería incluirse en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 11, opciones A y B). Además, el reglamento proporcionaría una tercera opción, C, que sería una combinación de las otras dos. Con arreglo a este enfoque, el solicitante de la inscripción estaría facultado para elegir el plazo de vigencia de la notificación inscrita pero sujeto a un plazo máximo autorizado, a fin de desalentar la elección de plazos excesivos (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párr. 88, y proyecto de guía sobre el registro, recomendación 11, opción C).

20. Si un Estado escoge la opción A, tal vez desee considerar la posibilidad de permitir que el solicitante de la inscripción reduzca el plazo legal de vigencia de una notificación inscrita en el registro si se prevé que la duración del acuerdo de garantía será más corto que el plazo legal de vigencia especificado de toda notificación inscrita en el registro. Sin embargo, la adopción de este enfoque daría por resultado gastos innecesarios en el diseño del registro, puesto que el autor de una inscripción estaría siempre autorizado y obligado, en todo caso, a cancelar una notificación inscrita en el registro si la obligación garantizada se cumple y el acuerdo de garantía queda sin efecto antes del vencimiento del plazo de vigencia legal.

21. El requisito, con arreglo a las opciones B y C, de que el solicitante de la inscripción indique en la notificación el plazo de vigencia de la notificación inscrita en el registro es un requisito de cumplimiento obligatorio, con el resultado de que una notificación en la cual no se indique el plazo de vigencia será rechazada. Los Estados quizá deseen considerar la posibilidad de diseñar el registro de manera que se incluya automáticamente un plazo de vigencia por defecto si no lo hace el solicitante de la inscripción. Se podría incluir en la reglamentación una disposición del tenor siguiente que recoja este enfoque: “Cuando en la notificación no se indique un plazo, la inscripción será válida durante [un período breve, por ejemplo, de cinco años, que será especificado por el Estado promulgante] años”.

22. Si el Estado promulgante opta por la opción B o C, sería conveniente diseñar el registro de manera que permita al solicitante de la inscripción elegir e indicar con facilidad en la notificación el plazo de vigencia deseado sin correr el riesgo de cometer un error por inadvertencia, por ejemplo, limitando la selección a plazos contados por años enteros a partir de la fecha de inscripción. A fin de asegurarse de que no existan contradicciones entre el régimen de operaciones garantizadas y el reglamento del registro, la opción que un Estado decida incorporar a su legislación debería corresponder a la opción escogida en su régimen de operaciones garantizadas.

23. Independientemente de que un Estado promulgue la opción A, B o C, las reglas que se apliquen al cálculo del período de vigencia en el derecho nacional se aplicarán al plazo de vigencia de una notificación inscrita en el registro, a menos que el régimen de operaciones garantizadas disponga otra cosa. Por ejemplo, la ley nacional puede disponer que cuando el cálculo se realice a partir del día de la

inscripción o del aniversario del día de la inscripción, el año comenzará a contarse a partir del principio de ese día. Además, cabe observar que en los casos en que la ley manda que el solicitante de la inscripción determine el plazo de vigencia de la inscripción de una notificación, se trata de un requisito obligatorio. Esto significa que si el plazo de vigencia de la inscripción no se hace constar en la notificación, esta notificación probablemente será rechazada.

24. Independientemente del enfoque que adopte el Estado promulgante a fin de determinar el período de vigencia de una inscripción, con arreglo a las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, se pierde la oponibilidad a terceros una vez que vence el plazo de vigencia a menos que: a) la garantía real pase a ser oponible a terceros antes de vencerse el plazo por algún otro método autorizado para ese tipo de bien gravado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 46); o b) se inscriba una notificación de modificación por la cual se prorrogue el plazo de vigencia de la inscripción. Si bien la oponibilidad a terceros de esa garantía real podría restablecerse mediante la inscripción registral de una nueva notificación, la garantía real surtiría efecto frente a terceros solo a partir del momento de efectuarse la nueva inscripción y, por regla general, estaría subordinada a los acreedores garantizados inscritos con anterioridad (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 47 y 96).

3. Momento en que puede inscribirse una notificación

25. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que se autorice la inscripción de una notificación antes de la constitución de una garantía real o de la conclusión de un acuerdo de garantía; esto se denomina generalmente “inscripción anticipada” (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrs. 98 a 101, y recomendación 67). Lo normal sería que esta norma se incluyese en el régimen de operaciones garantizadas. Según las prácticas legislativas del Estado promulgante, podría incluirse esta disposición en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 12).

26. Como ya se explicó (véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1, párr. 32), la inscripción registral no constituye una garantía real ni es necesaria para ello (véase también *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 33). Por consiguiente, en tanto que no se concluya el acuerdo de garantía y no se cumplan todos los demás requisitos exigibles para constituir una garantía real, el acreedor garantizado podrá verse frustrado por un tercero concurrente, por ejemplo, el comprador que adquiera derechos sobre los bienes gravados en el lapso que medie entre la inscripción anticipada y la constitución de la garantía real. Sin embargo, en general la inscripción registral asegurará al acreedor garantizado, una vez constituida la garantía real, la prelación respecto de cualquier otro acreedor garantizado que inscriba una notificación con posterioridad, independientemente del orden de constitución de las garantías reales concurrentes.

27. Si las negociaciones se abandonan después de efectuada la inscripción registral o por cualquier otra razón no llega a concertarse ningún acuerdo de garantía entre las partes, la fiabilidad y solvencia de la persona que figura como otorgante en la inscripción registral podría verse afectada negativamente por la existencia de la inscripción registral a menos que sea cancelada. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el solicitante de la inscripción (o, en caso de que se trate de un registro electrónico, el sistema del registro) esté obligado a notificar

oportunamente a la persona identificada en la notificación como otorgante, sobre la inscripción registral de la notificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 55, apartado c)). Por lo general el solicitante de la inscripción estará dispuesto a cancelar la inscripción registral, sea unilateralmente, sea a pedido de la persona que figura como otorgante en la notificación, si no se ha concertado ningún acuerdo de garantía entre las partes o si la garantía real a que se refiere la notificación se ha extinguido. Sin embargo, en caso de que el solicitante de la inscripción omita hacerlo o se niegue, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda recurrir a un procedimiento judicial o administrativo sumario para permitir que la persona que figura en la notificación como otorgante obligue a que se cancele la notificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72, apartado b)). En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, se recomienda asimismo que, si se concierta un acuerdo de garantía después de haberse efectuado la inscripción registral de una notificación pero sus estipulaciones no se corresponden con el contenido de la notificación inscrita, la persona identificada en ella como otorgante podrá valerse de este procedimiento para obligar a que se enmiende la notificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72, apartado a), recomendaciones 54, apartado d) y 72, apartados b) y c), así como A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párrs. 28 a 30).

4. Suficiencia de una notificación única

28. En un sistema de inscripción registral de notificaciones como el que se prevé en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrs. 10 a 14, y recomendación 57, así como A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1, párrs. 22 a 31 y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 21), no hay ninguna razón para que una notificación única no baste para obtener la oponibilidad a terceros con respecto a garantías reales presentes o futuras nacidas de acuerdos de garantía múltiples entre las mismas partes y sobre los bienes descritos en la notificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 68). El exigir una correspondencia unívoca entre cada notificación y cada acuerdo de garantía generaría gastos innecesarios y socavaría la capacidad del acreedor garantizado de responder con flexibilidad a sus cambiantes necesidades financieras sin temor de perder la prelación que le corresponde en virtud de la inscripción registral inicial. Por consiguiente, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la inscripción de una notificación única baste para lograr la oponibilidad a terceros de una o más garantías reales, sea que existan ya en el momento de hacerse la inscripción registral o se constituyan más tarde o que nazcan de uno o más acuerdos de garantía entre las mismas partes (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 68). Normalmente, esta regla figuraría en la ley sobre operaciones garantizadas. Sin embargo, según las prácticas legislativas del Estado promulgante, podría incluirse o reiterarse en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 13).

29. Conviene insistir en que la inscripción de una notificación logra la oponibilidad a terceros de las garantías reales nacidas de múltiples acuerdos de garantía solo en la medida en que la descripción de los bienes gravados consignada en la notificación corresponda con su descripción en cualquier acuerdo de garantía nuevo o enmendado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*,

recomendación 63). En caso contrario, la inscripción registral no cumpliría la función de alertar a los terceros que hicieran consultas sobre la posible existencia de una garantía real. En consecuencia, y en la medida en que cualquier acuerdo de garantía concertado entre las partes se refiera a bienes adicionales que no se describieron en la notificación inicial, haría falta una nueva notificación o una modificación de la notificación inicial, y la oponibilidad a terceros, así como la prelación, de la garantía real sobre estos bienes adicionales surtiría efecto solo a partir del momento de la inscripción registral de la nueva notificación o modificación.

5. Indización u otra forma de organizar la información del fichero del registro

30. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el criterio primario de la indización para fines de búsqueda y recuperación de las notificaciones inscritas en el registro de las garantías reales sea el identificador del otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrs. 31 a 36, y recomendación 54, apartado h)). A fin de poner en práctica esta recomendación, los Estados promulgantes deberían tratarla detalladamente en la reglamentación (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 14).

31. Si bien la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se refiere a la indización de la información del fichero del registro, la indización, desde el punto de vista técnico, no es la única forma de organizar la información de una base de datos de modo que sea posible encontrar lo que se busca. Por consiguiente, en el contexto de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, por indización debería entenderse cualquier método de organizar la información contenida en las notificaciones inscritas en el fichero del registro que permita localizar esa información mediante una búsqueda que emplee el identificador del otorgante como criterio de búsqueda.

32. La recomendación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* de que se utilice el identificador del otorgante como criterio primario de indización y búsqueda (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrs. 31 a 36 y recomendación 58) se basa en dos consideraciones. En primer lugar, a diferencia de lo que sucede con los bienes inmuebles, la mayoría de las categorías de bienes muebles no dispone de un identificador lo bastante singular para permitir hacer una búsqueda útil basada en los bienes. En realidad, en vista de la flexibilidad con que pueden describirse los bienes gravados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 14, apartado d), y 57), hay muchas formas de describirlos que resultarán suficientes (por ejemplo, su inclusión en una lista de artículos determinados o categorías concretas). En segundo lugar, constituir una garantía sobre bienes futuros o masas de bienes circulantes, como existencias o créditos por cobrar, resultaría complicado desde el punto de vista administrativo y tendría un costo prohibitivo si el acreedor garantizado tuviera que actualizar continuamente su notificación al producirse algún cambio en la masa de bienes ofrecida en garantía por el otorgante. Un sistema de indización y de consulta basado en el identificador del otorgante resuelve ese problema al permitir que el acreedor garantizado haga su garantía oponible a terceros mediante una única inscripción de una masa o categoría de bienes, existentes o futuros, pertenecientes a un mismo otorgante y gravados en virtud de uno o más acuerdos de garantía entre las mismas partes. Véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 68).

33. En los casos en que el bien gravado tiene una descripción única y el sistema de registro está organizado de manera que permita la búsqueda según el identificador del bien, un sistema basado en la indización y búsqueda a partir del otorgante tiene una desventaja en el contexto específico de las operaciones garantizadas. Con arreglo a las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, a menos que un otorgante venda o enajene un bien gravado en el curso normal de sus negocios, la garantía real, por lo general, habrá de seguir al bien que haya pasado a manos del cesionario (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 79 y 81). Sin embargo, la garantía real no saldrá a luz en una búsqueda del fichero del registro a partir del identificador del cesionario, lo cual podría perjudicar a terceros que tengan negocios con el bien en poder del cesionario y no estén enterados de la cadena histórica de la titularidad de dicho bien. Supóngase, por ejemplo, que el otorgante B, tras haber otorgado una garantía sobre su automóvil en favor de A, venda ese automóvil a C, quien, a su vez, se propone vender u otorgar una garantía sobre el automóvil a D. Suponiendo que D no sepa que C ha adquirido dicho bien del otorgante inicial B, D consultará el registro de las garantías reales basando su búsqueda únicamente en el identificador de C. En esa búsqueda no saldrá a luz la garantía inicial constituida por B en favor de A, porque dicha garantía fue inscrita bajo el identificador de su otorgante inicial B. Esto se conoce generalmente como el “problema A-B-C-D” (en cuanto a la cuestión de si debe obligarse a todo acreedor garantizado a modificar la notificación inscrita de su garantía para agregar al cesionario como nuevo otorgante, véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párrs. 8 a 11).

34. Para responder al “problema A-B-C-D”, algunos regímenes de las operaciones garantizadas prevén un mecanismo de indización y consulta suplementario basado en los bienes, de modo que el cesionario situado en el último eslabón de la cadena, D en el ejemplo, pueda determinar mediante una búsqueda del fichero del registro accesible al público si una garantía real ha sido otorgada por un predecesor en la titularidad a la persona con la que tiene negocios. En general, la indización y búsqueda basadas en los bienes se emplea solo para categorías específicas de bienes muebles de alto valor y muy duraderos, para los cuales existe un mercado de reventa y para cada uno de los cuales existe un número de serie fiable y único o un identificador alfanumérico equivalente (por ejemplo, vehículos automotores, remolques, casas rodantes, fuselajes y motores de aeronave, material rodante ferroviario, embarcaciones y motores de embarcación, que en lo sucesivo se denominarán “bienes con número de serie”). El mercado de vehículos automotores constituye un buen ejemplo. Normalmente los vehículos automotores son de alto valor y existe para ellos un mercado de reventa de considerable importancia. Además, la industria automotriz asigna un identificador alfanumérico único, comúnmente denominado número de identificación del vehículo, para identificar cada uno de los vehículos automotores según un sistema basado en normas emitidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Si para la inscripción registral del vehículo se exige la consignación del número de identificación y se permite la búsqueda mediante la referencia a ese número, se resuelve con ello el “problema A-B-C-D”, puesto que la consulta basada en el número de identificación del vehículo revelará todas las garantías reales otorgadas respecto del vehículo automotor de que se trate por cualquier propietario anterior. Otros tipos de bienes respecto de los cuales en ciertos regímenes se ha adoptado este enfoque basado en el “número de serie” son los remolques, las casas rodantes, los fuselajes y motores de

aeronave, el material rodante ferroviario, las embarcaciones y motores de embarcación.

35. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* examina, pero sin hacer ninguna recomendación al respecto, la cuestión del uso del número de serie o el identificador alfanumérico equivalente de un bien, como criterio de indización y búsqueda (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrs. 34 a 36). Las principales razones para adoptar este enfoque consisten en que la multiplicidad de criterios de búsqueda complicaría las consultas y crearía cargas innecesarias para sus autores. En todo caso, la adopción de un número de serie o su equivalente no es factible como criterio de búsqueda para la mayoría de los tipos de bienes muebles o para las masas de bienes circulantes presentes y futuros, como existencias o créditos por cobrar. Por consiguiente, si un Estado decide optar en la práctica por un sistema que utilice el número de serie de un bien como criterio supletorio de indización y de búsqueda, dicho sistema debería limitarse a los tipos de bienes de alto valor descritos *supra*. Además, con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas de los Estados que han adoptado este enfoque, la inscripción registral del número de serie es obligatoria para lograr la oponibilidad a terceros y obtener prelación solo frente a los tipos de reclamantes concurrentes que puedan resultar, potencialmente, más perjudicados por el problema “A-B-C-D” (especialmente, los cesionarios de los bienes gravados). Frente a otros tipos de reclamantes recurrentes, por ejemplo los acreedores del otorgante por decisión judicial o el administrador de la insolvencia, la inscripción registral de una notificación que no incluya información en el espacio indicado para consignar el número de serie seguirá siendo oponible a terceros siempre que en la notificación se describa suficientemente el bien gravado.

6. Integridad del fichero del registro

36. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que, si bien la gestión cotidiana del registro podrá delegarse a una entidad privada, el Estado retenga la responsabilidad de supervisar y gestionar el registro a fin de asegurarse de que funcione de conformidad con el régimen de las operaciones garantizadas para satisfacer las necesidades de sus usuarios (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párr. 47, y recomendación 55, apartado a)). Además, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda otras varias medidas para asegurar la integridad y seguridad del fichero del registro. Estas medidas son, entre otras: a) la obligación del registro de solicitar la identificación del solicitante de la inscripción y dejar constancia de su identidad; b) enviar sin tardanza copia de cualquier modificación o cancelación al solicitante de la inscripción; y c) mantener copias de seguridad del fichero del registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrs. 48 a 54, y recomendación 54, apartados b) a f)). A fin de garantizar la integridad del fichero del registro, el reglamento debería incluir reglas que pongan en práctica estas recomendaciones.

37. Entre otras medidas que pueden adoptarse para asegurar la integridad del fichero del registro cabe mencionar las siguientes. En primer lugar, el reglamento debería disponer que el personal del registro no podrá modificar ni retirar la información archivada en el fichero del registro, salvo disposición expresa en contrario de la ley y el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 15). En segundo lugar, el reglamento debería prever que la información consignada en una notificación inscrita en el registro podrá ser

enmendada solo mediante la inscripción de una notificación de modificación de conformidad con lo dispuesto en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 17).

38. Además, deben reducirse al mínimo las posibilidades de corrupción del personal del registro de la siguiente manera: a) diseñando el sistema del registro de manera que sea imposible para el personal del registro modificar la fecha y hora de inscripción o cualquier otra información ingresada por el solicitante de la inscripción; b) eliminando toda facultad discrecional del personal del registro para negar el acceso a los servicios del registro; c) instituyendo controles financieros que limiten estrictamente el acceso del personal al pago de derechos en efectivo (por ejemplo, exigiendo que el pago de los derechos se haga a un banco u otra institución financiera y haciendo que quede sujeto a confirmación por estos); y d) diseñando el sistema de registro de manera que pueda garantizar que en la copia archivada de las inscripciones registrales canceladas se preservan los datos consignados originalmente.

39. Además, debería dejarse bien en claro al personal del registro y a sus usuarios, entre otras cosas, que el personal del registro no está autorizado a proporcionar asesoramiento jurídico sobre los requisitos jurídicos para que las inscripciones registrales y consultas surtan efecto ni sobre los efectos jurídicos de las inscripciones y consultas efectuadas. Además, debería dejarse bien sentado que el personal del registro es responsable solamente de la supervisión de cómo funciona (o no funciona) el registro en la práctica, incluida la reunión de datos estadísticos sobre el número y los tipos de inscripciones registrales y consultas efectuadas, a fin de estar en condiciones de sugerir cualquier modificación necesaria de los procesos de inscripción y consulta y la correspondiente reglamentación.

40. Además, como ya se explicó (véase A/CN.9/WG.VI/WP.48/Add.1, párrs. 48 a 55), el registro debería diseñarse, de ser posible, de manera que se permita a los autores de inscripciones y consultas presentar ellos mismos, directa y electrónicamente, la información que ha de inscribirse o emplearse en una consulta, y no que tenga que hacerlo por ellos el personal del registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 54, apartado j)). En un registro puramente electrónico de este tipo, la función del personal del registro debería limitarse, esencialmente, a gestionar y facilitar el acceso electrónico por los usuarios, la tramitación de los derechos de inscripción y de consulta y la supervisión del funcionamiento y mantenimiento del registro. Si se adopta este enfoque, el reglamento debería dejar bien sentado que los usuarios son los únicos responsables de cualquier error u omisión que se deslice en el proceso de inscripción registral o consulta y serán también responsables de efectuar las correcciones o modificaciones necesarias (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 8).

7. Responsabilidad del registro

41. El Estado promulgante deberá determinar la forma en que ha de asignarse la responsabilidad por pérdidas o daños debidos a cualquiera de las causas siguientes: a) información o asesoramiento incorrectos o equívocos o rechazo injustificado de una solicitud de inscripción o de consulta por un funcionario del registro; y b) demoras o errores en la tramitación o una presentación incompleta de las inscripciones o de los resultados de las consultas imputables a fallas o defectos de funcionamiento del sistema. Como ya se dijo (véanse los párrs. 36 a 40 *supra*), si

bien en los casos en que el registro permite las inscripciones y consultas directas por los usuarios del registro la ley recomendada en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* limita la responsabilidad del registro a las fallas de funcionamiento del sistema, en general deja esta cuestión a criterio de los Estados promulgantes (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 56). En algunos Estados, parte de los derechos de inscripción y de consulta se guarda en un fondo para cubrir la posible responsabilidad del registro por pérdidas o daños sufridos por acreedores garantizados o terceros autores de consultas. En otros Estados hay mecanismos de seguro destinados a cubrir esa responsabilidad del registro. Por fin, en otros Estados donde los datos son ingresados en el fichero del registro por personal del registro y, por consiguiente, el riesgo de error y responsabilidad es demasiado grande, puede no preverse el pago de una suma compensatoria o puede existir una cifra máxima para cada pérdida.

8. Copia de la notificación inscrita en el registro

42. En vista de la importancia de la eficacia de la inscripción registral de una notificación para oponerla a terceros y asegurar la prelación de una garantía real, es esencial que el solicitante de la inscripción se cerciore de que la información consignada en la notificación se ha ingresado debidamente en el fichero del registro, con la fecha y hora correctas. Por consiguiente, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el autor de una inscripción pueda obtener una constancia de la inscripción efectuada tan pronto como la información consignada en la notificación sea ingresada en el fichero del registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrs. 49 a 51, y recomendación 55, apartado e)).

43. Además, el solicitante de la inscripción necesita que se le informe acerca de cualquier cambio que se introduzca en una notificación inscrita para poder tomar sin dilación las medidas apropiadas, a fin de proteger su posición en caso de que se haya efectuado una modificación o cancelación erróneamente. En consecuencia, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda además que el registro envíe sin tardanza copia de cualquier modificación efectuada en una notificación inscrita en el registro a la persona identificada en ella como el acreedor garantizado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrafo 52, y recomendación 55, apartado d)). El reglamento debería incluir disposiciones que pongan en práctica estas recomendaciones (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 16).

44. Además, el otorgante necesita un recibo de la copia de la notificación inscrita en el registro o una confirmación para asegurarse de que la información consignada en la notificación: a) corresponda a la autorización dada por el otorgante en el acuerdo de garantía o de otra índole, de existir un acuerdo; y b) se encuentre dentro de los límites de la autorización del otorgante para la inscripción registral. En consecuencia, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el solicitante de la inscripción esté obligado a enviar copia de la notificación inscrita en el registro al otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 55, apartado c)). También esta recomendación debería quedar reflejada en el reglamento.

45. El hacer recaer en el solicitante de la inscripción la obligación de enviar copia de la notificación al otorgante y no en el registro tiene por objeto evitar la creación

de una carga adicional para el registro, que podría afectar negativamente su eficiencia desde el punto de vista del tiempo y los costos. Si se parte del supuesto de que en la mayoría de los casos las inscripciones registrales se harán de buena fe y serán exactas, si el autor de una inscripción no cumple esa obligación solo se expondrá a sanciones menores y al resarcimiento de todo daño probado que haya resultado de ese incumplimiento (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrafo 51, y recomendación 55, apartado c)).

46. A fin de lograr una mayor eficiencia, el registro debería estar concebido, de ser posible, de manera que generase automáticamente una constancia electrónica de la inscripción registral y la enviase electrónicamente o, por ejemplo, como adjunto a un correo electrónico, al solicitante de la inscripción. Si el registro, en cambio, está obligado a enviar al solicitante de la inscripción copia de papel por correo ordinario y el solicitante de la inscripción, a su vez, tiene que reenviar la copia al otorgante, también por correo, se pueden producir demoras y problemas.

9. Modificación de la información consignada en una notificación inscrita en el registro

47. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el autor de una inscripción esté facultado para modificar la información consignada en la notificación inscrita en el registro inscribiendo una notificación de modificación en cualquier momento (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrafo 110 a 116, y recomendación 73). La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda también que el otorgante esté facultado, en ciertas circunstancias, para solicitar una modificación, mediante un procedimiento judicial o administrativo (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrafos 107 y 108, y recomendación 72). En vista de la importancia de estas recomendaciones, el reglamento podría recogerlas y, además, puntualizar la información que debería contener toda notificación de modificación (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 17).

48. Una notificación puede no reflejar o haber dejado de reflejar una relación financiera existente o prevista entre el acreedor garantizado y el otorgante identificado en la inscripción. Esto puede deberse a que, después de efectuada la inscripción, se hayan interrumpido las negociaciones entre las partes, estas hayan acordado agregar o suprimir bienes gravados, o haya llegado a su fin la relación financiera representada por la inscripción. En tal caso, la continuación de la presencia de la información en el fichero del registro limitará la capacidad de la persona identificada como otorgante para vender o crear una nueva garantía real sobre los bienes descritos en la inscripción. Ello se debe a que un posible comprador o acreedor garantizado se mostrará renuente a entablar negociaciones con el otorgante a menos que se cancele la inscripción existente.

49. Si bien la inscripción de una modificación por el acreedor garantizado exigiría la debida autorización del otorgante, una modificación debida a la cesión de la obligación garantizada, la subordinación o el cambio de dirección del acreedor garantizado o de su representante no debería requerir autorización del otorgante. Normalmente, el otorgante autoriza la inscripción registral de una notificación inicial, así como de cualquier modificación, en un solo documento de autorización. Y esa autorización única no requiere que el acreedor garantizado solicite varias

autorizaciones para efectuar distintas modificaciones (por ejemplo, para prorrogar el plazo de vigencia de la notificación inscrita en el registro).

50. Cabe observar que toda modificación supondrá un cambio en el contenido del fichero del registro mediante otra notificación, pero nunca un cambio en la información consignada en la notificación inicial, que podrá seguir siendo objeto de consultas en el fichero del registro accesible al público y, una vez vencido el plazo de vigencia de la notificación o una vez que esta haya sido cancelada, podrá localizarse en los archivos del registro (véanse los párrafos 51 a 53 *infra*).

10. Retiro de la información del fichero del registro accesible al público y archivo de esa información

51. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la información contenida en una notificación se retire del fichero del registro accesible al público una vez vencido el plazo de vigencia de la notificación inscrita o una vez que se inscriba una notificación de cancelación; en esa etapa, la información deberá archivar (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párrafo 109, y recomendación 74). El reglamento debería incluir normas que pongan en práctica estas recomendaciones (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendaciones 18 y 19).

52. En particular, el reglamento debería dejar bien sentado que la información retirada del fichero del registro accesible al público debe archivar de modo que sea posible recuperarla durante un período cuya determinación quedará a criterio de los Estados promulgantes (por ejemplo, por lo menos 20 años). La duración del período de archivo puede depender de la duración del período durante el cual puedan iniciarse demandas con arreglo a un acuerdo de préstamo. Por ejemplo, en algunos ordenamientos jurídicos no es posible entablar acción judicial después de transcurridos 15 años, contados desde la fecha en que tuvo lugar el acto en que se basaría la demanda. En esos ordenamientos, el reglamento del registro dispone que la información contenida en todas las notificaciones inscritas en el registro deben mantenerse en los archivos del registro durante 15 años; y si bien es posible que el período de 15 años sea prorrogado mediante el reconocimiento de la deuda por el deudor, el registro no está obligado a conservar la información en sus archivos más allá del plazo fijado inicialmente. Cabe observar que la recuperación de la información archivada puede ser necesaria para distintos fines, por ejemplo, para establecer la prelación en el caso de procedimientos judiciales o de insolvencia prolongados, o para los fines de la legislación fiscal o de blanqueo de dinero. En muchos Estados, la información consignada en notificaciones que han caducado o han sido canceladas puede conservarse en el fichero del registro accesible al público con la indicación de que esa información ha caducado o ha sido cancelada.

53. En otros Estados, donde es el registro el que consigna en el fichero la información que le ha sido presentada, el registro puede corregir los errores que haya cometido en el proceso de consignar tal información en su fichero. Ello tiene por objeto garantizar que el registro pueda corregir los errores cometidos al consignar en el fichero la información presentada en un formulario impreso (la exactitud de la información contenida en el impreso es responsabilidad del solicitante de la inscripción), pero no podrá someter a examen ni corregir la información que el autor de una inscripción introduzca electrónicamente, pues ello sería contrario a lo recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*

(véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 54, apartado d), que tiene por objeto limitar la función del registro y, por tanto, la probabilidad de error y la responsabilidad consiguiente). El registro podrá efectuar la modificación que corrija su error inscribiendo un formulario de corrección que identifique al empleado que hizo las correcciones y las correcciones efectuadas. Los Estados promulgantes que deseen permitir esas correcciones por parte del registro deberán prever normas sobre las consecuencias jurídicas de los errores cometidos por el registro al ingresar información en su fichero y, en particular, sobre si una “corrección” puede modificar el orden de prelación.

11. Idioma de la notificación

54. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se examina la cuestión del idioma de una notificación pero no se hace ninguna recomendación al respecto (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 44 a 46). En vista de la importancia de la cuestión, debería ser tratada en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 20).

55. A este respecto, se plantean dos cuestiones. En primer lugar, el idioma en que ha de expresarse la información consignada en la notificación y, en segundo lugar, el conjunto de caracteres en que ha de consignarse la información en la notificación. El reglamento debería especificar el idioma pero no es necesario que se ocupe del conjunto de caracteres autorizados siempre que se den a conocer a los usuarios (por ejemplo, en el sitio web del registro). Esto permitiría al registro revisar periódicamente el conjunto de caracteres.

56. Normalmente el idioma que ha de utilizarse para ingresar información en el registro será el idioma oficial o los idiomas oficiales del Estado bajo cuya autoridad funcione el registro, pero podría incluir también cualquier otro idioma que especifique ese Estado. En todo caso, los resultados de las consultas deberían expresarse en el idioma utilizado para ingresar la información en el fichero del registro. Además, en los casos en que el nombre del otorgante sea el identificador pertinente y el nombre correcto esté expresado con un conjunto de caracteres distintos de los empleados por el registro, este podría estar concebido de modo que pudiera ajustar o transliterar algunos caracteres incluidos en el nombre del otorgante a fin de armonizarlos con los caracteres utilizados por el registro. Lo mismo vale para el nombre del acreedor garantizado, la descripción de los bienes gravados y demás información que contenga la notificación si, por ejemplo, es preciso utilizar en la notificación el idioma hablado en el Estado extranjero del fabricante. Es posible que haya que hacer públicos (por ejemplo, en el sitio web del registro) los caracteres que han de transliterarse y la forma en que se efectuará la transliteración.

57. En los casos en que el otorgante sea una persona jurídica y la ley con arreglo a la cual fue constituida permita el uso de versiones lingüísticas alternativas de su nombre, el reglamento debería especificar que deben consignarse todas las versiones lingüísticas del nombre como identificadores separados del otorgante, en la medida en que ello sea compatible con el idioma especificado del registro. Esto es necesario para proteger a terceros que puedan estar negociando o haber negociado con el otorgante identificado por cualquiera de las versiones alternativas de su nombre y, por tanto, podrían consultar el registro utilizando esa versión.

58. Una forma de mitigar los diversos problemas que podrían plantearse por el hecho de que el identificador del otorgante esté expresado en un idioma distinto del utilizado por el registro podría consistir en emplear los números del documento de identidad personal como identificador del otorgante en lugar de su nombre (para un examen de esta cuestión, véase A/CN.9/WG.VI/WP.52, párrs. 11 y 12).

B. Recomendaciones 10 a 20

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las recomendaciones 10 a 20, tal como figuran en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.5. El Grupo de Trabajo quizás desee también observar que, por razones de economía, las recomendaciones no se incluyen en el presente documento en esta etapa pero se incluirán en el texto definitivo.]

(A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.3) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 22º período de sesiones

[Original: inglés]

ADICIÓN**Índice**

	<i>Párrafos</i>
IV. Información sobre la inscripción registral	1-56
A. Observaciones generales	1-56
1. Información requerida en una notificación inicial	1-23
2. Información sobre el acreedor garantizado	24-26
3. Descripción de los bienes gravados	27-35
4. Período de vigencia de la notificación inscrita	36
5. Importe monetario máximo por el que puede ejecutarse una garantía real	37-41
6. Información incorrecta o insuficiente	42-56
B. Recomendaciones 21 a 27	

IV. Información sobre la inscripción registral**A. Observaciones generales****1. Información requerida en una notificación inicial**

1. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que, para que una notificación inicial de inscripción sea eficaz, se requiera única y exclusivamente la siguiente información: a) el identificador y la dirección del otorgante; b) el identificador y la dirección del acreedor garantizado o de su representante; c) una descripción del bien gravado; d) la duración de la inscripción registral, si el Estado promulgante adopta, en su régimen de las operaciones garantizadas, la opción de permitir que el solicitante de la inscripción fije el período de vigencia de la notificación; y e) la suma monetaria máxima por la que el acreedor garantizado podrá ejecutar la garantía real, si el Estado promulgante opta por requerir esta información en su régimen de las operaciones garantizadas (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 65 a 97 y la recomendación 57). En el reglamento debería reafirmarse y complementarse esta recomendación (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 21). En los párrafos que figuran a continuación se examina cada uno de los elementos requeridos del contenido de una notificación.

2. Conforme a lo ya tratado (véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrs. 1, 2, 7 y 9), el solicitante de la inscripción deberá indicar la información requerida en el espacio previsto a tal efecto y en la forma prescrita de la notificación (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendaciones 9 y 21). Por ejemplo, si el solicitante de la inscripción indicara el identificador del otorgante en el espacio destinado al acreedor garantizado, el registro no tendría un motivo para rechazar la notificación. No obstante, la inscripción de la notificación puede carecer de validez, con el resultado de que la garantía real a la que se refiera no se haga oponible a terceros. Sin embargo, esto tampoco sería un motivo para rechazar la notificación. Además, los identificadores del otorgante y del acreedor garantizado deberían determinarse sobre la base de documentos actuales y oficiales y deberían constituir sus respectivos identificadores en el momento de la inscripción. Por último, sus direcciones deberían ser las direcciones actuales de las que tuviera conocimiento el solicitante de la inscripción en el momento de inscribir su notificación.

a) Información sobre el otorgante

i) Observaciones generales

3. Como ya se ha explicado (véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrs. 38 a 43), en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que la información consignada en las notificaciones se indice en función del identificador del otorgante. A fin de garantizar que en una consulta del registro se encuentren todas las garantías reales que pueda haber otorgado una persona, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* ofrece además una orientación explícita sobre lo que constituye el identificador correcto del otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 58 a 60). En el reglamento debería darse una orientación detallada a fin de que el autor de una notificación tenga la seguridad de que su inscripción será jurídicamente eficaz y de modo que quien consulte el registro pueda confiar plenamente en el resultado de su búsqueda (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendaciones 22 a 24).

4. No es inhabitual que una persona constituya una garantía real sobre sus bienes a fin de garantizar una obligación adeudada por un tercero deudor (incluidos los terceros garantes de la obligación contraída por el otorgante). Dado que la función de la inscripción es dar a conocer toda garantía real que se haya podido constituir sobre los bienes descritos en la notificación, en el reglamento debería quedar claro que la información requerida es el identificador y la dirección del otorgante que sea el propietario de los bienes gravados, o que tenga derechos sobre ellos, y no la información sobre el tercero deudor de la obligación garantizada (o sobre un mero garante de la obligación del deudor).

5. Además, cuando haya más de un otorgante, el reglamento deberá especificar que los identificadores y las direcciones deberán indicarse en el espacio de la notificación designado a tal efecto, especificando por separado los identificadores de los distintos otorgantes. Este requisito es necesario, ya que el identificador del otorgante es el criterio de búsqueda mediante el cual las personas que consultan el registro encuentran las notificaciones (véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párrs. 31 a 36). Para facilitar el proceso de inscripción, convendría diseñar la forma prescrita de la notificación de modo que en la misma notificación puedan indicarse por separado los distintos identificadores y las distintas direcciones de los diversos otorgantes. Si bien el solicitante de la inscripción podría lograr el mismo resultado

inscribiendo una notificación para cada otorgante, este proceso sería más engorroso, pues el solicitante de la inscripción tendría que repetir en cada notificación toda la información requerida para una notificación.

ii) *Personas físicas o personas jurídicas*

6. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se prevén recomendaciones distintas para determinar el identificador del otorgante en función de si este último es una persona física, una persona jurídica u otra entidad (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 59 y 60). Por consiguiente, las notificaciones se indizarán o se organizarán de otro modo en el fichero del registro en función de criterios distintos, que dependerán de la categoría en que entre el otorgante.

7. Este enfoque tiene repercusiones en el proceso de inscripción y búsqueda. A fin de asegurar que la información consignada en una notificación se inscriba correctamente en el fichero del registro para que pueda ser encontrada por quien la busque, el reglamento debería aclarar que el solicitante de la inscripción deberá especificar el identificador y la dirección del otorgante en los espacios previstos para indicar la información relativa a la categoría pertinente de otorgante. Para ello, en el formulario prescrito de la notificación y en el formulario de solicitud de búsqueda deberían figurar espacios distintos para inscribir el identificador y la dirección de los otorgantes de cada categoría (véanse los formularios en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.6).

iii) *Identificador de las personas físicas*

8. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que, cuando el otorgante sea una persona física, se inscriba como identificador de este, exigible para que la inscripción surta efecto, el nombre del otorgante que figure en un determinado documento oficial (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 59). A fin de aplicar esta recomendación, habría que especificar en el reglamento los tipos de documento oficial que para el Estado promulgante constituyan fuentes fidedignas del nombre del otorgante. En el cuadro que figura a continuación se ilustra el tipo de enfoque que cabría adoptar, si bien cada Estado promulgante debería determinar, según su nomenclatura, los tipos de documento oficial u otras fuentes que sean más apropiados (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 22).

Condición del otorgante	Identificador del otorgante
Nacido en el Estado promulgante y nacimiento registrado en ese Estado	Nombre que figure en la partida de nacimiento o en el documento oficial equivalente
Nacido en el Estado promulgante pero sin haberse registrado en él su nacimiento	1) Nombre que figure en el pasaporte actualmente válido 2) A falta de pasaporte actualmente válido, nombre que figure en el documento oficial equivalente, como la tarjeta de identidad o la licencia para la conducción de vehículos
No nacido en el Estado promulgante pero naturalizado en ese Estado	Nombre que figure en el certificado de nacionalidad

No nacido en el Estado promulgante ni nacionalizado como ciudadano suyo	1) Nombre que figure en el pasaporte actualmente válido expedido por el Estado del que el otorgante sea ciudadano 2) A falta de un pasaporte extranjero actualmente válido, nombre que figure en la partida de nacimiento o en el documento oficial equivalente que se haya emitido en el lugar de nacimiento del otorgante
Ninguno de los supuestos anteriores	Nombre que conste en dos documentos oficiales cualesquiera emitidos por el Estado promulgante, siempre que esos nombres sean idénticos (por ejemplo, en la tarjeta de la seguridad social, del seguro médico o la tarjeta fiscal)

9. Es igualmente importante establecer normas claras sobre qué componentes del nombre que figura en el documento oficial han de indicarse en la notificación prescrita (por ejemplo, apellido, seguido por el primer nombre, seguido por el segundo nombre) e incluir distintos espacios en la notificación prescrita para consignar cada componente. Al decidir qué componentes habrán de exigirse, el Estado promulgante debería tener en cuenta las convenciones locales observadas con los nombres, así como la medida en que los documentos oficiales expedidos localmente especifican los distintos componentes del nombre. También debería ofrecerse orientación para situaciones excepcionales. Por ejemplo, en caso de que el nombre del otorgante consista en una sola palabra, el reglamento debería prever que esa palabra deberá consignarse en el espacio reservado para el apellido y el sistema del registro debería estar diseñado de modo que no rechace las notificaciones que dejen en blanco los espacios previstos para los nombres (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 22, opción A)

10. El Estado promulgante tal vez desee considerar la conveniencia de hacer cotejos electrónicos de los nombres consignados en las notificaciones inscritas y los nombres que aparecen en otras bases de datos. A este respecto, deben tenerse en cuenta dos cuestiones. La primera es la responsabilidad del registro. Este se hace responsable de que la base de datos a la que está conectado sea completa, exacta y esté actualizada. La segunda cuestión es el efecto jurídico de ofrecer servicios de cotejo electrónico. Una opción consistiría en que el reglamento prevea que un documento encontrado por el cotejo sea jurídicamente suficiente para identificar al otorgante. Según este criterio, el cotejo electrónico desplazaría la responsabilidad jurídica de identificar correctamente al otorgante del solicitante de la inscripción al registro, exponiéndolo de este modo a una posible responsabilidad. La otra opción sería disponer que este servicio no tenga ningún efecto jurídico y que siga siendo responsabilidad del solicitante de la inscripción que recurre al cotejo electrónico el asegurarse de que el identificador del otorgante encontrado en la base de datos externa sea el correcto. Este último enfoque está más de acuerdo con las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

11. En algunos Estados muchas personas pueden tener el mismo nombre, con el resultado de que una búsqueda puede sacar a luz múltiples otorgantes, todos con igual nombre. Para resolver este problema, la *Guía sobre las Operaciones*

Garantizadas recomienda que, en caso necesario, se incluya en la notificación información adicional además del nombre del otorgante (como la fecha de nacimiento del otorgante o su número de identificación personal u otro número de identificación emitido por el Estado promulgante) para identificar de manera inequívoca al otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 59). Todo Estado que desee llevar a la práctica esta recomendación adicional debería especificar en el reglamento el tipo de información adicional que ha de consignarse y si es obligatorio consignar esa información en la inscripción registral para que surta efecto o si la inclusión queda a criterio del solicitante de la inscripción (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 22, opción B).

12. Que el Estado promulgante disponga o no la inclusión en la notificación del número de un documento de identidad u otro documento oficial expedido por ese Estado, a manera de información adicional, dependerá de tres importantes condiciones. En primer lugar, que el sistema de registro bajo cuya autoridad se expiden los números de los documentos de identidad sea de alcance suficientemente universal y fiable para garantizar que a cada persona física se le asigne un número permanente y único. En segundo lugar, que la política pública del Estado promulgante permita la divulgación pública del número del documento de identidad u otro documento que el Estado asigne a sus ciudadanos o residentes o a ambos. En tercer lugar, que exista un registro documental fehaciente u otra fuente donde los terceros puedan hacer búsquedas y verificar objetivamente si un número determinado corresponde al de un otorgante particular. Si se dan estas tres condiciones, el uso del número del documento de identidad o de otro documento oficial expedido por el Estado sería la forma ideal de identificar de manera inequívoca al otorgante. Sin embargo, como ya se dijo, el enfoque recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* es que la información adicional, sea en la forma del número de un documento de identidad o de otra forma, podrá requerirse solamente cuando sea necesario para identificar al otorgante de manera inequívoca (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 59) y solo como requisito adicional aparte del de consignar el nombre del otorgante (véase el proyecto de guía sobre el registro, opción B).

13. En vista de las recomendaciones relativas al conflicto de leyes de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (como, por ejemplo, la recomendación 203, según la cual la ley aplicable a la constitución de toda garantía real sobre bienes corporales, su oponibilidad a terceros y su grado de prelación debería ser la ley del Estado en que esté situado el bien), la ley del Estado promulgante (incluido el reglamento de su registro) podría ser aplicable a una garantía real constituida por un otorgante extranjero. De este modo, el reglamento exige la anotación del número del documento de identidad u otro documento oficial expedido por el Estado para identificar al otorgante de manera inequívoca, pero todavía será necesario que el reglamento aborde los casos en que el otorgante no es ciudadano o residente del Estado promulgante o en que, por cualquier otra razón, no se le haya asignado ningún número. El Estado promulgante podría disponer en el reglamento, por ejemplo, que el número del pasaporte extranjero del otorgante o el número de algún otro documento oficial extranjero será un sustituto suficiente.

iv) *Identificador de las personas jurídicas*

14. Cuando los otorgantes sean personas jurídicas, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el identificador exigible para que la inscripción surta efecto sea el nombre que aparezca en la escritura constitutiva de la persona jurídica (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 60). El reglamento debería recoger y complementar esta norma. En particular, habría que redactar el reglamento de manera que quedase claro que la escritura constitutiva pertinente ha de abarcar cualquier tipo de instrumento (ya se trate de un contrato privado, de una ley o un decreto) que sea la fuente jurídica de la condición del otorgante como persona jurídica con arreglo a la ley que rigió su constitución (véase el proyecto sobre el registro, recomendación 23).

15. Prácticamente todos los Estados llevan un registro de las sociedades mercantiles para archivar los datos, incluido el nombre, de toda sociedad mercantil constituida con arreglo al derecho interno de ese Estado. En muchos Estados, al inscribirse una persona jurídica en el registro, se le asigna un número de inscripción único y fiable. Si al Estado promulgante le preocupa la posibilidad de que varias personas jurídicas compartan el mismo nombre, el reglamento podría disponer que se incluya ese número en la notificación a manera de información adicional para identificar de manera inequívoca al otorgante (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 23, opción B).

16. Cuando el otorgante es una persona jurídica su nombre incluye normalmente abreviaturas genéricas (por ejemplo, “S.L.”, “S.A.”, “Inc.”, etc.) o palabras (como “sociedad limitada”, “sociedad anónima”, etc.) indicativas del tipo de sociedad o de persona jurídica de que se trata. El reglamento debería dejar bien sentado que estas abreviaturas o palabras constituyen un componente optativo del identificador del otorgante en el sentido de que una búsqueda realizada con su inclusión o sin ella, o utilizando una versión equivocada de estas, localizaría de todos modos la inscripción pertinente. El enfoque optativo protegería a los autores de inscripciones que no consignen la abreviatura genérica correcta o la omitan por completo. Sin embargo, podría reducir la transparencia para los terceros autores de consultas puesto que la búsqueda produciría todos los otorgantes que sean personas jurídicas, independientemente de su clase, que compartan ese nombre específico.

17. Según cuál sea la ley aplicable a la constitución de la persona jurídica, la escritura u otro instrumento constitutivo puede contener variantes contradictorias del nombre (por ejemplo, podría referirse a la entidad en distintos lugares, como “la ABC S.A” o “ABC S.A” o “ABC”). Lo ideal sería que el reglamento proporcionara orientación sobre qué parte de la escritura constitutiva ha de tratarse como fuente fidedigna del nombre del otorgante para los fines de la inscripción registral. Sería menester establecer reglas complementarias para tener en cuenta los casos en que la persona jurídica haya sido constituida en otro Estado y, en particular, decidir si el nombre o el número de inscripción que figura en el registro público de ese otro Estado podrá utilizarse como identificador de la persona jurídica en el Estado promulgante.

v) *Casos especiales*

18. El reglamento también deberá proporcionar algunas directrices adicionales sobre el identificador del otorgante requerido cuando este no encaje plenamente ni

en la categoría de persona física ni en la de persona jurídica (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 24). La cuestión aquí no es si el otorgante tiene capacidad jurídica para constituir una garantía real, sino más bien cómo ha de consignarse su identificador en la notificación. En el cuadro que figura a continuación se dan ejemplos de las distintas situaciones que deben considerarse, con ejemplos de posibles identificadores. Los Estados promulgantes tal vez deseen considerar la posibilidad de elegir y adaptar estos ejemplos a su propia legislación.

Condición del otorgante	Identificador del otorgante
Masa de la insolvencia, por conducto de un representante de la insolvencia	Nombre de la persona insolvente, anotado de conformidad con las normas aplicables a los otorgantes que son personas físicas o jurídicas, según el caso, con indicación en un espacio aparte previsto para tal efecto de que el otorgante es insolvente
Consortio o empresa conjunta	Nombre del consorcio o de la empresa conjunta tal como figura en la escritura constitutiva, consignado en el espacio previsto para anotar el identificador de la persona jurídica
Fideicomisario o representante encargado de la administración de la masa	Nombre del fideicomisario o del representante encargado de la administración de la masa de conformidad con las normas aplicables a los otorgantes que son personas físicas o jurídicas, según el caso, con la indicación, en un espacio aparte, de que el otorgante actúa como fideicomisario o representante encargado de la administración de la masa
Otra entidad	Nombre de la entidad tal como figura en la escritura constitutiva, consignado de conformidad con las normas aplicables a los otorgantes que son personas jurídicas

19. Si se trata de un negocio de propietario único, aun cuando el negocio sea llevado bajo un nombre comercial distinto del de su propietario, el reglamento debería disponer que el identificador del otorgante sea el nombre del propietario consignado con arreglo a las normas aplicables a los otorgantes que son personas físicas. El nombre del propietario único no es un dato fiable, pues el propietario puede cambiarlo a voluntad. Sin embargo, podrá consignarse como otorgante adicional en la notificación.

20. Como ya se indicó, los sistemas de inscripción electrónica de notificaciones deberán diseñarse de modo que permitan a los autores de inscripciones seleccionar un espacio en que figure la categoría con su designación apropiada (por ejemplo, masa de la insolvencia, consorcio o empresa conjunta, fideicomiso o masa patrimonial, etc.) en vez de anotar esa designación en el espacio reservado al otorgante. Otra posibilidad sería que la notificación contuviera un espacio o renglón para que el solicitante de la inscripción indicara la designación correcta.

vi) *Dirección del otorgante*

21. Con arreglo a la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, la dirección del otorgante forma parte del contenido requerido de la notificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, apartado a)). Este enfoque contribuye a identificar de manera inequívoca al otorgante cuando resulte necesario hacerlo como, por ejemplo, cuando el nombre del otorgante es común (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 59). La dirección del otorgante es pertinente para los fines del envío al otorgante de copias de las notificaciones inscritas (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 55, apartados c) y d)) y permite a los terceros que realicen búsquedas ponerse en contacto con el otorgante para obtener mayor información. En consecuencia, el solicitante de la inscripción deberá consignar la dirección actual del otorgante. Sin embargo, la dirección del otorgante no forma parte del identificador del otorgante en el sentido de que constituya un criterio de búsqueda. En el reglamento deberían recogerse estas recomendaciones y, en caso necesario, complementarlas. Además, el sistema del registro debería diseñarse de modo que se indicara a los autores de inscripciones que consignaran la dirección en un espacio aparte, distinto del destinado al identificador del otorgante.

22. Algunos Estados no exigen la consignación de la dirección del otorgante cuando su seguridad personal pueda aconsejar que no figuren los detalles de la dirección en un documento accesible al público. En los casos en que se reconozca esta excepción, el reglamento podría especificar la necesidad de consignar una casilla de correo o una dirección postal similar no residencial. Otra posibilidad es que las partes interesadas se pongan en contacto con el acreedor garantizado (cuya dirección debe ser consignada en la notificación) para obtener mayor información sobre el otorgante.

23. La dirección del otorgante desempeña un papel menos importante en los sistemas en que el identificador del otorgante debe incluir información adicional con el fin de identificar al otorgante de manera inequívoca (por ejemplo, la fecha de nacimiento o el número de un documento de identidad expedido por el Estado), a diferencia de los sistemas en que el identificador exigido es solo el nombre del otorgante, con el resultado de que una búsqueda puede sacar a luz múltiples garantías reales otorgadas por diferentes otorgantes que tienen el mismo nombre (véanse los párrs. 11 y 12 *supra*).

2. Información sobre el acreedor garantizado

24. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el identificador del acreedor garantizado o del representante del acreedor garantizado, junto con su dirección, sea incluido en la notificación presentada al registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, apartado a)). El reglamento debería recoger esta recomendación y, en caso necesario, complementarla (véase el proyecto de guía para el registro, recomendación 25).

25. En el reglamento debería especificarse que las mismas normas relativas al identificador aplicables al otorgante también se aplicarán al acreedor garantizado o su representante. Sin embargo, como se explica más adelante (véase el párr. 46), puesto que el identificador del acreedor garantizado o su representante no constituye un criterio de búsqueda, una rigurosa exactitud no es esencial para que la

inscripción surta efecto. En consecuencia, aun cuando el reglamento requiera información adicional para el identificador usado para identificar de manera inequívoca al otorgante (por ejemplo, la fecha de nacimiento o el número de un documento personal de identidad), no es necesario hacer extensivo este requisito al acreedor garantizado.

26. El reglamento debería dejar bien sentado que el autor de una inscripción, que puede ser el acreedor garantizado o su representante, podrá consignar en la notificación el identificador del acreedor garantizado o el de un fideicomisario, mandatario u otro representante. Este enfoque tiene por objeto facilitar, por ejemplo, los préstamos sindicados, pues bastará consignar en la notificación el identificador del banco principal o su nominatario. También tiene por objeto proteger la privacidad del acreedor garantizado. Los derechos del otorgante no se ven afectados pues este se encuentra en relación directa con el acreedor garantizado (o el banco principal en el caso de un acuerdo de préstamo sindicado) y ya conoce la identidad del acreedor garantizado. Los derechos de terceros tampoco se verán afectados siempre que la persona identificada en la notificación como acreedor garantizado esté autorizada, de hecho, para actuar en nombre del acreedor garantizado real en cualquier comunicación o controversia relacionada con la garantía real.

3. Descripción de los bienes gravados

a) Observaciones generales

27. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la descripción de los bienes gravados a los que se refiere la garantía real relacionada con la inscripción registral sea un componente necesario para que una notificación surta efecto (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, apartado b)). Este enfoque permite a los terceros que tienen interés en los bienes de una persona (como posibles acreedores garantizados, compradores, acreedores judiciales y el representante de la insolvencia de esa persona) determinar qué bienes de esa persona pueden estar gravados por una garantía real. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda también que, en general, se considere suficiente la descripción de los bienes gravados a fin de que surtan efecto tanto el acuerdo de garantía como la inscripción registral, siempre que permita identificar con certeza razonable los bienes gravados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 14, apartado d), y 63). Según el carácter del bien gravado, la descripción puede ser específica o genérica. Por ejemplo, si el bien gravado es una pintura concreta, la descripción contenida en la notificación deberá especificar el título de la pintura, el nombre del pintor y el año en que se hizo la pintura. En cambio, si los bienes gravados pertenecen a categorías genéricas, tales como todas las existencias de una galería de arte, bastaría describirlos con fórmulas como “todos los cuadros”, “todas las obras de arte” o “todos los bienes muebles del otorgante”.

28. El reglamento debería recoger esta recomendación y, en caso necesario, complementarla (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 26). En particular, el reglamento debería disponer explícitamente que la descripción de los bienes gravados en la notificación podrá ser específica o genérica siempre que permita identificarlos con certeza razonable. El reglamento debería precisar también que se entenderá que una descripción que remita a todos los bienes de una categoría genérica o a todos los bienes de un otorgante incluirá los bienes futuros de esa

determinada categoría sobre los cuales el otorgante adquiera derechos durante el período de vigencia de la notificación. Si la forma prescrita de la notificación limita el número de caracteres que puedan anotarse en el espacio destinado a la descripción de los bienes gravados y hace falta espacio adicional (por ejemplo, para identificar los bienes gravados con mayor detalle), el sistema del registro debería diseñarse de modo que permita incluir información adicional en un anexo a la notificación. En general esto es necesario solamente cuando la notificación se hace en un formulario impreso; con el formato electrónico, no hay problemas de espacio.

b) Descripción de bienes “con número de serie”

29. Como ya se explicó (véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrs. 33 a 35), la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* examina, pero sin hacer ninguna recomendación al respecto, el uso de un número de serie u otro identificador alfanumérico único como identificador independiente para los fines de la inscripción registral y las consultas (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 34 a 36).

30. Sin embargo, no estaría en contradicción con lo recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* que un Estado promulgante requiriese en su régimen de las operaciones garantizadas que el solicitante de la inscripción ingrese el número de serie de determinadas categorías de bienes gravados en un espacio separado previsto para ese fin, siempre que ese número permita identificar el bien con certeza razonable (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 14, apartado d), 57, apartado b), y 63). Si se adopta este enfoque, debería limitarse a los bienes de alto valor para los cuales existe un importante mercado de reventa, pues limitaría las posibilidades de un acreedor garantizado de hacer que una garantía real fuera plenamente oponible a terceros sobre los futuros bienes con número de serie del otorgante mediante una sola inscripción registral. En efecto, el acreedor garantizado tendría que efectuar una nueva inscripción o modificar la descripción de los bienes gravados en la notificación inscrita para anotar el número de serie de cada nuevo bien a medida que los vaya adquiriendo el otorgante.

31. Si el Estado promulgante decide adoptar este enfoque, el reglamento debería dejar bien sentado que la anotación de un número de serie en el espacio previsto para ese fin no será exigible cuando los bienes pertinentes formen parte de las existencias del otorgante. En este último caso, bastará la anotación de una descripción genérica en el espacio general destinado a la descripción de los bienes gravados. Esto se debe a que en el caso de las existencias no se presenta el llamado “problema A-B-C-D” (véase A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párr. 43), puesto que los compradores que adquieren existencias del otorgante original en el curso ordinario de los negocios del otorgante toman las existencias, en todo caso, libres de toda garantía real (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 81, apartado a)).

c) Descripción del producto

32. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que una garantía real se haga extensiva automáticamente a cualquier producto identificable que dimane de los bienes gravados, a menos que las partes en el acuerdo de garantía hayan estipulado otra cosa (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*,

Introducción, sec. B “producto” y recomendación 19). En los casos en que la garantía real sobre los bienes gravados originales se haya hecho oponible a terceros mediante la inscripción registral, se plantea la cuestión de si el acreedor garantizado necesita modificar la descripción de los bienes gravados contenida en la notificación inicial a fin de incluir una descripción del producto y asegurarse así de que su garantía real sobre el producto sea oponible a terceros.

33. Si el producto consiste en efectivo (por ejemplo, dinero o derecho al cobro de una suma), la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la oponibilidad de una garantía inscrita anteriormente sobre los bienes gravados originales se extienda automáticamente al producto. Lo mismo cabe decir cuando el producto obtenido es de un tipo que corresponda a la descripción que se dio en la notificación inscrita del bien gravado (por ejemplo, si la descripción abarca “todos los bienes corporales” y el otorgante ha intercambiado una pieza de su equipo por otra; véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 39).

34. Sin embargo, si el producto no consiste en efectivo ni está comprendido en la descripción hecha en la notificación inscrita, el acreedor garantizado deberá modificar, en un breve plazo contado a partir del nacimiento del producto, la notificación inscrita añadiendo una descripción del producto a fin de dotar a su garantía sobre este producto de oponibilidad a terceros, con efecto a partir de la fecha de la inscripción inicial de su garantía (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 40). Esa modificación es necesaria, pues de lo contrario un tercero que consulte el registro no podrá identificar qué categorías de bienes en posesión del otorgante constituirían el producto.

d) Descripción de los bienes gravados incorporados a un bien inmueble

35. Como cualquier otro tipo de bien, un bien corporal que ha sido o será incorporado a un bien inmueble tendrá que describirse en la notificación inscrita en el registro general de garantías reales de manera que permita su identificación con certeza razonable (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 14, apartado d), 57, apartado b), y 63)). Si bien una descripción genérica del bien puede bastar para este fin, el solicitante de la inscripción puede necesitar también hacer una inscripción en el registro de la propiedad inmobiliaria a fin de asegurarse de que su garantía real sea oponible a terceros que adquieran una garantía y la inscriban en el registro pertinente de la propiedad inmobiliaria. En estos registros, normalmente las inscripciones se indizan o se organizan por remisión a un terreno o solar específico y no al identificador del otorgante. De este modo, para que la notificación también se pueda inscribir en el registro de la propiedad inmobiliaria, la descripción del bien contenida en la notificación deberá incluir una referencia al identificador específico del inmueble. Además, es posible que haya que modificar las normas que rigen las inscripciones en los registros de la propiedad inmobiliaria para permitir la inscripción de notificaciones y la descripción genérica de los bienes gravados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párr. 104). Por otra parte, si el otorgante de la garantía real sobre el bien no es el propietario del inmueble de que se trata, la notificación puede tener que identificar también al propietario del bien si dicha identificación es necesaria para la indización de la notificación en el registro de la propiedad inmobiliaria.

4. Período de vigencia de la notificación inscrita

36. Como ya se vio (A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrs. 25 a 32), si un Estado opta, en su régimen de las operaciones garantizadas, por permitir a los autores de inscripciones que elijan el período de vigencia de la notificación inscrita, el reglamento deberá recoger ese enfoque (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 69, y el proyecto de guía sobre el registro, recomendaciones 11 y 21, apartado a) iv)). Además, el sistema del registro debería estar concebido de modo que permitiese al solicitante de la inscripción elegir e indicar fácilmente en la notificación el plazo deseado sin riesgo de cometer errores por inadvertencia (por ejemplo, limitando la elección a años enteros contados desde la fecha de la inscripción).

5. Importe monetario máximo por el que puede ejecutarse una garantía real

37. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se prevé que, para facilitar la obtención de préstamos contra el valor residual del bien gravado, algunos Estados pueden exigir una indicación, en la notificación inscrita, de la suma monetaria máxima por la que pueda ejecutarse la garantía real (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 92 a 97, y recomendación 57, apartado d); para la indicación correspondiente de esa suma en el acuerdo de garantía, véase la recomendación 14, apartado d)).

38. La finalidad de este enfoque puede ilustrarse con el siguiente ejemplo. Una empresa dispone de un bien con un valor estimado de mercado de 100.000 dólares. La empresa solicita la apertura de un crédito renovable por una cuantía máxima de 50.000 dólares (incluidos capital, intereses y costos). El acreedor está dispuesto a concederle el préstamo con la condición de que se le otorgue una garantía real sobre dicho bien. El otorgante consiente en otorgar la garantía, pero dado que el préstamo máximo especificado en el acuerdo de garantía y en la notificación es de solo 50.000 dólares y el bien tiene un valor de 100.000 dólares, el otorgante deseará tal vez reservarse la posibilidad de obtener más tarde otro préstamo garantizado de otro acreedor, ofreciéndole una garantía real sobre el mismo bien, con cargo a su valor residual. Normalmente, el segundo acreedor se sentirá reacio a otorgar un préstamo por temor a que el primer prestamista pueda conceder más adelante préstamos que sobrepasen la cantidad inicial de 50.000, en cuyo caso tendría prelación conforme a la regla general de que prima la garantía inscrita en primer lugar. Pero si se impone la obligación de especificar el máximo cobrable al ejecutar la garantía, el segundo acreedor del ejemplo no sentirá temor alguno de que el acreedor titular de la primera garantía real inscrita pueda ejecutarla por un monto superior a 50.000 dólares (incluidos capital, intereses y costos), con lo que quedará disponible el valor residual para resarcir su propio crédito, en el supuesto de que el otorgante incurra en incumplimiento.

39. En los Estados que opten por esta posibilidad, el reglamento deberá dejar bien sentado que el importe monetario máximo y las monedas pertinentes deberán indicarse en el espacio previsto para ese fin en la notificación. Cada Estado deberá determinar si la suma ha de consignarse en cifras, letras o ambas cosas. Quizá el registro pudiera diseñarse de manera que acepte letras o dígitos en todos los espacios, salvo en los destinados al importe máximo y a la duración de la inscripción, en los cuales se aceptarían solamente dígitos. Algunos Estados permiten al solicitante de la inscripción indicar, o seleccionar de un menú, la moneda en que

se ha hecho el préstamo. En esos Estados, será preciso abordar las consecuencias jurídicas de una diferencia entre la cuantía máxima especificada en la notificación y la cantidad realmente adeudada. Si el monto máximo especificado en la notificación es mayor que la cuantía realmente adeudada en el momento de ejecutarse la garantía, el acreedor garantizado solo tendrá derecho a ejecutar su garantía real hasta el monto que efectivamente le sea adeudado. En el supuesto contrario de que la cuantía máxima especificada en la notificación sea menor que el monto realmente adeudado, el acreedor garantizado podrá ejecutar su garantía real únicamente por el monto máximo indicado en la notificación (y valerse de los recursos que se ofrezcan a un acreedor no garantizado con respecto al saldo pendiente). Si embargo, de no existir ningún otro reclamante concurrente, el acreedor garantizado podrá ejecutar su garantía real hasta el monto realmente adeudado.

40. Al mismo tiempo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce que es un enfoque igualmente válido no indicar en la notificación la cuantía máxima para facilitar así la concesión de crédito por el acreedor garantizado inicial. Este enfoque parte de los siguientes supuestos: a) el primer acreedor garantizado inscrito en el registro será la fuente financiera más satisfactoria a largo plazo o la que ofrecerá más probabilidades de conceder financiación, especialmente a pequeñas empresas en su fase inicial de desarrollo, siempre que ese acreedor se sienta seguro de que retendrá la prelación con respecto a toda financiación que se conceda al otorgante en el futuro; b) el otorgante no se encontrará en una posición negociadora lo bastante sólida como para pedir al primer acreedor garantizado inscrito que consigne un monto máximo cobrable realista en la notificación (el acreedor garantizado, en cambio, procurará fijar una cuantía excesiva a fin de cubrir toda concesión de crédito en el futuro, lo que, por lo general, el otorgante no estará en condiciones de rechazar); y c) el segundo acreedor al que el otorgante se dirija para obtener financiación estará posiblemente en condiciones de negociar con el primer acreedor garantizado inscrito en el registro un acuerdo de subordinación del primero al segundo en favor de todo crédito que otorgue el segundo por el valor residual actualizado del bien gravado. En los Estados que adopten este enfoque, el reglamento no tendrá que incluir una norma que exija la inclusión de la suma máxima en la notificación inscrita (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 21, apartado a) v)).

41. De este modo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* admite que hay razones en pro de los dos enfoques y recomienda que los Estados adopten la política que sea más compatible con las prácticas de financiación eficientes existentes en ellos y, en particular, con las prácticas del mercado crediticio en que se basa cada enfoque. Como ya se dijo, el reglamento debería adoptar un enfoque que se corresponda con el enfoque adoptado en el régimen de las operaciones garantizadas del Estado promulgante.

6. Información incorrecta o insuficiente

a) Información sobre el otorgante

42. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que la inscripción de una notificación surta efecto solo si facilita el dato correcto para identificar al otorgante o, en caso de que tenga alguna indicación incorrecta, si se puede recuperar mediante una búsqueda en el archivo del registro a partir del identificador correcto (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV,

párrs. 66 a 77 y recomendación 58). El reglamento debería recoger esta recomendación (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 27, apartado a)).

43. Por consiguiente, un error en el identificador del otorgante cometido por el solicitante de la inscripción podría privar de eficacia a la notificación inicial o a una notificación de modificación del identificador del otorgante, con el resultado de que se perdería la oponibilidad a terceros de la garantía real. El criterio para determinar la eficacia de la inscripción no debería depender de la índole tal vez trivial o insignificante del error cometido, sino de que ese error impida o no localizar la información consignada en el archivo del registro en una búsqueda efectuada usando el identificador correcto del otorgante. Ello es así porque el identificador del otorgante es el criterio de búsqueda para recuperar la información presentada en una notificación e ingresada en el archivo del registro. Se trata de un criterio objetivo puesto que: a) aun cuando el autor de una búsqueda sepa que existe una garantía y que ha sido inscrita, la búsqueda no dará de todos modos resultado si la notificación correspondiente no se puede obtener consultando el archivo del registro a partir del identificador correcto del otorgante; y b) la inscripción carecerá de eficacia aun cuando la persona que impugne su validez no haya sufrido, de hecho, un daño imputable a ese error.

44. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no incluye una recomendación en cuanto a cuál será el efecto de un error en algún dato complementario sobre el otorgante que no sea su identificador, por ejemplo, un error en su dirección o en su fecha de nacimiento (a menos que esta información adicional sea necesaria para identificar de manera inequívoca al otorgante, en cuyo caso, lo que se acaba de decir *supra* sobre un error en el identificador del otorgante sería aplicable a la información adicional). En el reglamento debería incluirse orientación sobre este problema (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 27, apartado b)). Por analogía con el criterio general recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* respecto de cualquier error en los datos personales del acreedor garantizado, el reglamento debería prescribir que un error en los datos adicionales del otorgante que no formen parte del identificador no invalidará la notificación inscrita a no ser que dificulte gravemente una consulta correcta del registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 64). Por ejemplo, si la búsqueda desemboca en una variedad de otorgantes que tengan el mismo nombre que la persona buscada por el autor de la consulta, pero el error en la información adicional sobre el otorgante es tan grave que lleve al autor de la consulta a creer que el otorgante indicado en la notificación no es la persona de su interés, una notificación que consigne a ese otorgante puede resultar carente de validez.

45. Además, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no se trata la situación en que en una notificación se enumere a más de un otorgante y se produzca un error solamente en el identificador de uno de los otorgantes enumerados en la notificación. En este caso, por analogía con la recomendación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* con respecto a un error cometido en la descripción de solamente algunos de los bienes gravados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 65), el reglamento debería disponer que un error de este tipo no privaría a la notificación inscrita de validez con respecto a los demás otorgantes, siempre que estos estuvieran suficientemente identificados

(véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 27, apartado c)). De conformidad con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, esta misma norma debería recogerse en el reglamento en el caso de las notificaciones que describen múltiples bienes gravados y se comete un error solo en la descripción de uno de ellos (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 27, apartado c)).

b) Información sobre el acreedor garantizado

46. Puesto que la información relativa al acreedor garantizado no constituye un criterio de indización ni de búsqueda, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que un error del solicitante de la inscripción en el identificador o en la dirección del acreedor garantizado o de su representante solo invalidará la inscripción de la notificación si ese error puede frustrar una búsqueda correcta de esa notificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 64). Por ejemplo, si el acreedor garantizado es identificado en la notificación como el banco AAA y la búsqueda en el registro da un resultado con el nombre de una entidad diferente como acreedor garantizado, la notificación inscrita puede no ser inválida (el banco AAA puede haber cambiado de nombre, haberse fusionado con otro banco o haber sido vendido). No obstante, siempre es importante inscribir dichos datos con exactitud en lo esencial, dado que el autor de una consulta deberá valerse del identificador y la dirección del acreedor garantizado o su representante que figuren en el archivo del registro para enviar toda notificación que haya de dar con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas (por ejemplo, notificar una enajenación extrajudicial de un bien gravado; véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 149 a 151). Además, el otorgante puede necesitar esa información para dirigir una petición escrita al acreedor garantizado de cancelación o de modificación de una notificación determinada (*Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72, apartado a)).

c) Descripción de los bienes

i) Observaciones generales

47. Con arreglo a la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, si el autor de una inscripción omite mencionar un bien o cierto tipo de bien en la notificación, es posible que la garantía real pierda validez para ser opuesta a terceros sobre el bien o el tipo de bien omitido. Sin embargo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que un error leve en la descripción de un bien gravado no prive a la notificación inscrita de validez a menos que esa falta induzca gravemente a error en una búsqueda razonable (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 64). Además, conforme a la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, de no satisfacerse en la inscripción el criterio de invalidez por “inducción grave a error”, esa inscripción será inválida solo con respecto a los bienes descritos equivocadamente u omitidos y la garantía real seguirá siendo oponible a terceros con respecto a los demás bienes que fueron descritos con suficiente claridad (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 65). El reglamento debería contener recomendaciones similares (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 27, apartados b) y c)).

ii) Bienes con número de serie

48. Como ya se ha indicado, en una notificación puede ser necesario describir los bienes registrados con su número de serie haciendo referencia a dicho número y al tipo de bien, si ello es preciso para permitir razonablemente su identificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 14, apartado d), 57, apartado d), y 63). En tal caso, un error en el número de serie y tipo del bien deberá tratarse de la misma manera que cualquier otro error en la descripción del bien. Esto significa, en general, que un ligero error en el número de serie no invalida la notificación inscrita, salvo que esa falta pueda inducir gravemente a error al autor de una consulta correcta (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 64 y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 27, apartado b)).

49. Como ya se dijo (véase A/CN.9/WG.VI/ WP.52/Add.2, párrs. 33 a 35), en los Estados cuyo régimen de las operaciones garantizadas exija que el número de serie de determinados bienes se consigne e indice como criterio independiente de búsqueda para que la garantía real sea plenamente válida y tenga prelación respecto de determinadas clases de terceros que son reclamantes concurrentes, podría hacerse una analogía con la recomendación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* aplicable al identificador incorrecto o insuficiente del otorgante en una notificación. En consecuencia, una notificación con el número de serie incorrecto solo tendrá validez si una búsqueda efectuada en el archivo del registro por el número de serie correcto diera resultado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 58).

50. En los ordenamientos jurídicos que adoptan este último enfoque, el reglamento también tendrá que abordar las consecuencias de un error cometido en el identificador del otorgante o en el número de serie pero no en ambos. El reglamento debería disponer que los dos deben consignarse correctamente en la notificación para que la inscripción tenga validez. En consecuencia, de haber un error en el identificador del otorgante o en el número de serie por el que resultara imposible encontrar la notificación al buscarla utilizando el identificador correcto o el número de serie correcto, la inscripción de esa notificación sería inválida o haría que la garantía real correspondiente gozase de menor prelación que las de ciertos reclamantes concurrentes especificados en el régimen de las operaciones garantizadas (por ejemplo, los cesionarios o arrendatarios de los bienes gravados del otorgante original).

iii) Período de validez de la inscripción registral

51. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que un error en cuanto al plazo de vigencia de la notificación inscrita en el registro no la prive de validez (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 66). El reglamento debería incluir una recomendación análoga (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 27, apartado e)). Sin embargo, esta recomendación debe condicionarse a la importante salvedad de que se debe dar amparo a todo tercero que se haya fiado de tal indicación equivocada (en lo que respecta al amparo del otorgante contra la inclusión no autorizada en la notificación de una suma máxima, véanse los párrafos 55 y 56 *infra*).

52. En consecuencia, si el solicitante de la inscripción consigna una duración mayor que la que se proponía, el amparo brindado a terceros pierde importancia porque un tercero que se fíe de la indicación incorrecta no resultará perjudicado. En efecto, la notificación inscrita le alertará del riesgo de que posiblemente exista una garantía real, por lo que podrá adoptar medidas para protegerse contra dichos riesgos. Dado que en el archivo del registro no habrá nada que dé a conocer que el acreedor garantizado tenía la intención de indicar un plazo más corto, la falta cometida por este no inducirá de modo alguno en error al tercero que consulte el registro. Por consiguiente, el error en cuanto a la duración de la validez contenido en la notificación inscrita no deberá invalidarla. Sin embargo, cuando la garantía real a la que se refiere la notificación haya caducado de hecho (por ejemplo, por pago de la obligación garantizada y por extinción de todo compromiso de crédito), el otorgante podrá pedir al acreedor garantizado que enmiende o cancele la notificación para reflejar la duración correcta. Si el acreedor garantizado no lo hiciera así en el plazo de días que especifique el régimen de las operaciones garantizadas después de recibir la petición escrita del otorgante, este podrá exigir la modificación o la cancelación de la notificación por un procedimiento judicial o administrativo sumario (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72, apartados a) y b)).

53. Sin embargo, cuando el período de vigencia fijado por ley o la duración incluida por el solicitante de la inscripción es más corto que el período de vigencia que se había tenido intención de establecer, la inscripción caducará al cumplirse el período especificado y la garantía real dejará ser oponible a terceros, a menos que se la haya hecho oponible por algún otro método antes de caducar la inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 46). Como ya se dijo, si bien el acreedor garantizado puede volver a establecer la oponibilidad a terceros mediante la inscripción de una nueva notificación, su garantía real será oponible a terceros solo a partir del momento en que se efectúe la nueva inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 47 y 96).

iv) *Importe monetario máximo y repercusiones del error*

54. En el caso de los Estados que optan por exigir que se consigne en la notificación la cifra máxima por la cual puede ejecutarse una garantía real, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que una indicación incorrecta en la notificación inscrita de la suma máxima no haga que la notificación pierda su validez (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 66). El reglamento debería incluir una recomendación similar (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 27, apartado e)).

55. Sin embargo este criterio está, a su vez, sujeto a la salvedad de que deberá protegerse a todo tercero que se haya fiado de la indicación incorrecta de la cuantía monetaria máxima en la notificación inscrita. Por tanto, cuando la suma máxima indicada en la notificación sea superior a la cuantía máxima convenida en el acuerdo de garantía o a la suma realmente adeudada, no será necesario proteger a terceros ya que su decisión de anticipar fondos al otorgante estará normalmente basada en la cuantía indicada en la notificación. Cabe señalar que el otorgante también estará protegido en esta situación pues podrá pedir al acreedor garantizado o, si este no actúa a su debido tiempo, a un órgano judicial u administrativo que, por un procedimiento sumario, enmiende la notificación corrigiendo la suma indicada a fin

de que el otorgante pueda obtener financiación con cargo al valor residual del bien gravado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72).

56. Sin embargo, cuando la suma máxima indicada en la notificación sea inferior a la cuantía máxima estipulada en el acuerdo de garantía o la cantidad realmente adeudada, deberá preverse la protección de todo tercero que se hubiera fiado del monto máximo especificado en la notificación (al abrir un crédito garantizado suponiendo que podrá ejecutar su garantía con cargo al valor residual del bien tras restar la suma indicada en la notificación). Análogamente, deberá protegerse a un acreedor judicial que trate de ejecutar una sentencia favorable en la creencia de que el valor residual del bien, por encima de la cifra indicada en la notificación, estará disponible para satisfacer su reclamación judicial. La forma de amparar los intereses de los terceros será limitar frente a ellos el derecho del acreedor garantizado a ejecutar su garantía, de modo que no rebase la cuantía máxima indicada erróneamente por el acreedor garantizado en la notificación inscrita (con respecto al derecho del acreedor a reclamar la suma realmente adeudada véase el párrafo 39 *supra*).

B. Recomendaciones 21 a 27

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar las recomendaciones 21 a 27, tal como se reproducen en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.5. El Grupo de Trabajo quizá desee observar también que, por razones de economía, las recomendaciones no se han incluido en el presente documento, en esta etapa, pero se incluirán en el texto definitivo.]

(A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 22º período de sesiones

[Original: inglés]

ADICIÓN

Índice

	<i>Párrafos</i>
V. Información sobre la modificación o cancelación de una notificación	1-30
A. Observaciones generales	1-30
1. Modificación voluntaria	1-22
2. Cancelación voluntaria	23-25
3. Corrección de caducidad o cancelación errónea	26-27
4. Modificación o cancelación obligatorias	28-30
B. Recomendaciones 28 a 31	
VI. Consultas	31-41
A. Observaciones generales	31-41
1. Criterios para efectuar la consulta	31-36
2. Resultado de la consulta	37-41
B. Recomendaciones 32 y 33	
VII. Derechos de inscripción y de consulta	42-48
A. Observaciones generales	42-48
B. Recomendación 34	

V. Información sobre la modificación o cancelación de una notificación**A. Observaciones generales****1. Modificación voluntaria****a) Observaciones generales**

1. Puede ser necesario modificar la información consignada en el registro a fin de señalar que ha cambiado la relación entre el acreedor garantizado y el otorgante. Eso se hace normalmente por medio de una modificación en que se indican los cambios introducidos en la información que figura en la notificación inscrita (con excepción de los errores cometidos en el registro al incorporar la información en el fichero, una vez que se inscribe una notificación no hay manera de editarla, y todo cambio habrá de hacerse en forma de notificación o aviso de modificación posterior; véase

la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72). Puede ser necesario introducir una modificación, por ejemplo, para añadir, cambiar o suprimir información en una notificación inscrita o para renovar su plazo de vigencia.

2. Normalmente la modificación no se hace suprimiendo la información ya consignada y sustituyéndola por la nueva. Por el contrario, la modificación se añade a la información consignada en la notificación inscrita inicial, de modo que la persona que consulte pueda encontrar y examinar tanto la información consignada originalmente como la posterior. Ni el solicitante de la inscripción ni el director del registro podrán sustituir ningún dato que ya esté inscrito, y, por consiguiente, el archivo deberá diseñarse en consecuencia.

3. Todo acreedor garantizado debería estar en condiciones de modificar o cancelar una notificación en cualquier momento y en la medida en que corresponda. Si bien para introducir determinadas modificaciones se necesitaría la autorización del otorgante, en relación con otras modificaciones, como la que se haga para consignar la cesión de la obligación garantizada, la subordinación, o el cambio de dirección del acreedor garantizado o de su representante, no se debería exigir esa autorización. Normalmente el otorgante autorizaría la inscripción registral de una notificación inicial, así como la de toda notificación o aviso de modificación, en un solo documento de autorización. Con esa autorización única, no se necesitaría que el acreedor garantizado solicitara varias autorizaciones para efectuar distintas modificaciones (por ejemplo, para prorrogar la validez de la inscripción registral). Ese es el enfoque que se recomienda en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 71 y 73).

4. Para efectuar una modificación, el solicitante de la inscripción deberá indicar determinada información en el espacio correspondiente de la notificación de modificación, a saber, el número de inscripción de la notificación a que se refiere la modificación y toda otra información adicional o nueva información que corresponda (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 28, apartado a)). El registro asignará fecha y hora a cada notificación de modificación (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 10). El Estado promulgante tal vez desee considerar la posibilidad de diseñar el sistema de registro de modo que permita al solicitante de la inscripción notificar una sola modificación por vez (por ejemplo, el cambio del identificador del otorgante) o varias modificaciones juntas (por ejemplo, la adición de un nuevo otorgante y la supresión de bienes gravados; véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 28, apartado e)). El primer criterio puede ser más sencillo, pero el segundo, mucho más económico. En todo caso, debe quedar claro que, si primero hay una cesión de la obligación garantizada y se inscribe una notificación en la que se identifica al nuevo acreedor garantizado, y después cambian los bienes gravados, únicamente el cesionario podrá introducir ese cambio. Por otra parte, como en el caso de la información consignada en la notificación inicial, la información que figura en un aviso de modificación presentado por el solicitante de la inscripción no puede ser verificada ni modificada sustancialmente por los administradores del registro, ya que este solo sirve de archivo de la información que recibe. De modo análogo, las consecuencias jurídicas de una modificación estarán determinadas por las normas sustantivas del régimen de las operaciones garantizadas.

b) Modificación del identificador del otorgante

5. Toda modificación del identificador del otorgante indicada en la notificación inscrita (por ejemplo, de resultados de un cambio de nombre posterior) puede socavar la función de publicidad del registro desde el punto de vista de los terceros que hagan negocios con el otorgante después de haberse modificado ese dato. Como ya se ha mencionado, el identificador del otorgante es el principal criterio de indización y de búsqueda, razón por la cual una consulta basada en el nuevo nombre del otorgante no revelará la existencia de una garantía real inscrita con el antiguo nombre. Cabe señalar que en un sistema de registro en que se utilice el número del carné de identidad expedido por el Estado para determinar al otorgante, en lugar de su nombre, es menos probable que se plantee ese problema, ya que ese número de identificación suele ser siempre el mismo.

6. Para abordar ese problema, el reglamento debería reconocer el derecho del acreedor garantizado a inscribir una notificación de modificación a efectos de consignar el nuevo identificador del otorgante. Si bien el hecho de no presentar una modificación no debería bastar para que la garantía real dejase de ser oponible a terceros, en general o retroactivamente, debería protegerse a las partes que hicieran negocios con el otorgante después de haberse modificado su identificador, pero antes de inscribirse la notificación de modificación. En consecuencia, las normas aplicables deberían disponer que, si el acreedor garantizado tuviera la posibilidad de inscribir una notificación de modificación con objeto de consignar el nuevo identificador del otorgante y no lo hiciera dentro de un breve “período de gracia” establecido (por ejemplo, de 15 días), contado a partir del momento en que se hubiera modificado ese dato, su garantía real dejaría de ser oponible frente a los compradores, arrendatarios, licenciarios y demás acreedores garantizados que adquirieran derechos sobre el bien gravado después de modificarse la identificación del otorgante y antes de inscribirse la modificación. Este es el enfoque recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 61). Normalmente esa norma estaría prevista en el régimen de las operaciones garantizadas, en el que se debería indicar el momento en que comenzaría a correr el período de gracia, ya sea la fecha de la modificación o el momento en que el acreedor garantizado se hubiera enterado efectivamente de ella. Si bien en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda el primer criterio, algunos Estados adoptan el segundo, de resultados de lo cual la garantía sigue siendo oponible a los terceros que adquieran derechos sobre el bien gravado antes de que el acreedor garantizado se entere de la modificación. Debería ofrecerse orientación, asimismo, sobre lo que constituye una modificación del identificador, en particular, en el contexto de las fusiones de sociedades, y las consecuencias de no efectuar una modificación en esas circunstancias.

7. En el reglamento debería quedar claro que el solicitante de la inscripción debería consignar el nuevo identificador del otorgante en el espacio del aviso de la modificación previsto para añadir un otorgante, sin suprimir la información relativa al otorgante anterior. De esa manera, toda búsqueda que se haga, ya sea mencionando la identificación del otorgante anterior o la del nuevo otorgante, revelará la notificación inscrita. Habida cuenta de que se asignaría fecha y hora a la notificación de modificación, y que esta estaría vinculada en el fichero del registro a la notificación inicial, ese método ofrecería una solución sencilla y no causaría confusión alguna.

c) Transferencia de un bien gravado

8. Cuando el otorgante transfiera, arriende o licencie un bien gravado, la garantía real acompañará al bien gravado que haya pasado a manos del cesionario (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 79). Eso crea un problema análogo al que plantea el cambio de identificador del otorgante con posterioridad a la inscripción, ya que consultar el registro utilizando el identificador del cesionario, del arrendatario o del licenciatario no servirá para revelar una garantía real registrada con el identificador del otorgante (el cedente, el arrendador o el licenciante). En consecuencia, para proteger a los terceros que quieran negociar con un bien gravado que se encuentre en posesión del beneficiario de la transmisión, el sistema de registro debe permitir al acreedor garantizado que presente una notificación de modificación (o una nueva notificación) a fin de dejar constancia del identificador y la dirección del beneficiario de la transmisión, arrendatario, o licenciatario en calidad de nuevo otorgante.

9. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se examinan las repercusiones de la transmisión del bien gravado en lo que respecta a la eficacia de la garantía real frente a los terceros que adquieran derechos sobre el bien transmitido por el cedente, pero la única recomendación que se formula es que el Estado regule esa cuestión en sus leyes (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 78 a 80 y recomendación 62).

10. En algunos Estados se prevé que la inscripción siga en vigor sin que se haga modificación alguna para indicar el identificador del cesionario como nuevo otorgante. En otros, por el contrario, rige una norma equivalente a la aplicable al cambio de identificador del otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 61, y los párrafos 5 a 7 *supra*). Según este enfoque, el hecho de no modificar la inscripción para añadir el identificador del beneficiario de la transmisión como nuevo otorgante adicional no hace que la garantía real deje de ser oponible a terceros en general. Sin embargo, si el acreedor garantizado no inscribe la modificación dentro del breve “período de gracia” (por ejemplo, 15 días) posterior a la transmisión, la garantía real no podrá ser invocada frente a los compradores, arrendatarios, licenciarios ni a otros acreedores garantizados que negocien con el bien gravado después de efectuada la transmisión, pero antes de inscribirse la modificación. Otros Estados adoptan un enfoque análogo, con la importante reserva de que el período de gracia concedido al acreedor garantizado para inscribir la modificación empieza a correr sólo a partir del momento en que este tenga conocimiento realmente de la transmisión. En otros Estados, por último, la inscripción de una modificación de esta índole es puramente optativa y la falta de una modificación no afecta la oponibilidad a terceros ni la prelación de la garantía real (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 78 a 80).

11. Si el Estado promulgante elige el primero o el segundo enfoque, debería incluir en su reglamento una disposición que permitiera al acreedor garantizado inscribir una notificación de modificación para añadir un nuevo otorgante (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 28, apartado a)). Los acreedores garantizados deben entender que la información sobre el otorgante original no debe suprimirse, puesto que eso daría lugar a que la garantía real ya no fuera oponible frente al otorgante original y, por consiguiente, tampoco frente al cesionario.

d) Subordinación de la prelación

12. Conforme al régimen recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, un acreedor garantizado con prelación puede subordinar su prelación en cualquier momento, unilateralmente o mediante acuerdo en favor de cualquier otro reclamante concurrente existente o futuro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 94). Como los terceros no se ven perjudicados por la subordinación, no es necesario que el acreedor garantizado subordinante o el beneficiario de la subordinación (suponiendo que uno o ambos hayan inscrito una notificación relativa a sus derechos en el registro) enmiende la inscripción para dejar constancia del cambio del orden de prelación. Sin embargo, en algunos casos pueden desear hacerlo. En consecuencia, el registro debería admitir la posibilidad de que se inscribiera una notificación de modificación en que se reflejase la subordinación.

e) Cesión de la obligación garantizada y transmisión de la garantía real

13. Todo acreedor garantizado puede ceder la obligación garantizada. Como en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que la garantía real, en su calidad de derecho accesorio, se transfiera conjuntamente con la obligación garantizada, lo que da lugar a que el cesionario de la obligación pase a ser, en realidad, el nuevo acreedor garantizado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 25 y 48). Según el criterio recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, no se necesita una modificación de la notificación inicial para añadir al cesionario como nuevo acreedor garantizado con objeto de preservar la validez de la inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 75). Habida cuenta de que el identificador del acreedor garantizado no es un criterio de indización ni de búsqueda, las consultas no inducirán a errores de importancia debido al cambio de identidad del acreedor garantizado. No obstante, el acreedor garantizado original (el cedente) por lo general no deseará tener que seguir atendiendo a las solicitudes de información de las personas que hagan consultas y el nuevo acreedor garantizado (el cesionario) deseará asegurarse de recibir toda notificación o comunicación relativa a su garantía real.

14. En consecuencia, debería permitirse al acreedor garantizado original o al nuevo acreedor garantizado, con el consentimiento del acreedor garantizado original, inscribir una notificación de modificación a efectos de hacer constar el identificador y la dirección del nuevo acreedor garantizado. Si este último no inscribe la modificación, el acreedor garantizado original seguirá teniendo la posibilidad de modificar la información presentando una notificación de modificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 111). En cualquier caso, el sistema de registro debería admitir que el resultado de la búsqueda revelara si la modificación fue inscrita por el acreedor garantizado original o por el nuevo acreedor garantizado.

15. Otra cuestión pertinente a la cesión de la obligación garantizada es el deber del acreedor garantizado de revelar la identidad del cesionario por solicitud del otorgante. Si se inscribe una notificación de la cesión de la obligación garantizada, conforme al régimen recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* el solicitante de la inscripción queda obligado a transmitir una copia de esa notificación al otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*,

recomendación 55, apartado c)). Sin embargo, independientemente de que se inscriba o no la notificación, el acreedor garantizado está obligado a declarar la cesión y la identidad del cesionario al otorgante, si este último lo solicita. En cualquier caso, revelar esa información no es una función que incumba al registro, sino una obligación impuesta por el derecho sustantivo que ha de cumplirse al margen del sistema de registro.

f) Adición de nuevos bienes gravados

16. Tras la celebración del acuerdo de garantía original, el otorgante podrá concertar la constitución de una garantía real sobre bienes que no estaban incluidos en la notificación inscrita. En ese caso, el régimen de las operaciones garantizadas y el reglamento deberían permitir al acreedor garantizado que modificara la notificación inicial a fin de añadir la descripción de los nuevos bienes gravados. Si bien el acreedor garantizado podría obtener el mismo resultado inscribiendo una nueva notificación con respecto a los nuevos bienes, la inscripción de la modificación siempre sería más eficiente y garantizaría que el plazo de vigencia de la inscripción fuese el mismo respecto de los bienes originales y de los nuevos bienes. Independientemente del método que se elija, la garantía real sobre los nuevos bienes gravados podrá invocarse frente a terceros únicamente a partir de la fecha de la inscripción en el registro de la modificación o de la nueva notificación, según el caso (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 70). La razón de este enfoque es que la consulta del fichero del registro por terceros antes de la inscripción de la modificación o de la nueva notificación no revelaría que se ha otorgado una garantía real sobre los nuevos bienes gravados.

17. Una vez que el otorgante haya cumplido parcialmente la obligación garantizada, puede tener derecho a recibir una parte de los bienes liberados de la garantía real con arreglo al acuerdo de garantía. El acreedor garantizado puede estar obligado entonces a modificar la notificación inscrita con objeto de suprimir los bienes gravados pertinentes. La modificación se hace efectiva en el momento de su inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 70).

g) Supresión de bienes gravados

18. El acreedor garantizado puede tener diversas razones para desear suprimir bienes gravados de la descripción de los bienes que figura en la notificación inicial. Por ejemplo, el otorgante puede haber reembolsado parcialmente la obligación garantizada a condición de que la garantía real se extinguiera con respecto a determinados bienes, o la descripción hecha en la notificación inicial puede haber sido demasiado amplia y el otorgante puede haber exigido al acreedor garantizado que modificara la notificación inicial a fin de que se reflejara el verdadero alcance de los bienes gravados en virtud de la garantía real relacionada con la notificación. En consecuencia, el sistema de registro debería admitir la inscripción de otra modificación por la que se suprimieran los bienes gravados descritos en la notificación de modificación.

h) Cambio de descripción de los bienes gravados

19. Por otra parte, mientras el acuerdo de garantía siga en vigor, pueden cambiar algunas de las características de los bienes gravados descritos en la notificación

inscrita inicialmente. Por ejemplo, la descripción puede haber sido “muebles negros de madera de cerezo”, pero posteriormente el otorgante puede haberlos pintado de marrón. Así pues, la descripción incluida en la notificación inscrita inicialmente ya no coincide con la descripción real del bien y, a fin de disipar dudas acerca de su exactitud, el acreedor garantizado puede querer modificarla. Esa modificación no daría lugar a una nueva fecha de prelación, como en el caso de la notificación de una modificación por la que se añadan nuevos bienes. En consecuencia, el sistema de registro debería admitir que el solicitante de la inscripción diera una nueva descripción de los bienes gravados e indicara en la notificación que se trata de un “cambio”.

i) Prórroga del plazo de vigencia de la inscripción

20. Después de efectuar una inscripción y antes de que expire su plazo de vigencia, es posible que el autor de esta necesite prorrogarla. Las normas aplicables a la inscripción deberían confirmar que el plazo de vigencia de una notificación inscrita podrá prorrogarse mediante la inscripción de una notificación de modificación en cualquier momento, antes de que expire (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 69). Si, por el contrario, fuera necesario inscribir una nueva notificación, ese requisito socavaría la prelación original del acreedor garantizado y la eficacia de su garantía real frente a terceros, ya que la nueva notificación podría hacerse valer frente a terceros únicamente a partir del momento en que se inscribiera.

21. Como ya se indicó (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.3, párr. 36), los Estados pueden adoptar varios criterios con respecto al plazo de vigencia de una notificación inscrita. En los Estados en que el plazo de vigencia está establecido por ley, la prórroga debe ser de un período suplementario igual al plazo previsto en la ley. En los Estados que permitan al solicitante de la inscripción decidir el plazo de vigencia, también debería permitírsele decidir la duración de la prórroga, sin perjuicio de cualquier límite máximo aplicable que el Estado pueda imponer a esa opción. Según este último criterio, el solicitante de la inscripción que, por ejemplo, elija un plazo de cinco años para la notificación inscrita inicialmente debería estar autorizado para elegir un plazo de prórroga de tres o siete años. En los Estados que no limiten el plazo de vigencia, no existiría la necesidad de prorrogarlo y la inscripción seguiría siendo válida hasta que se cancelara.

j) Modificación global

22. Tanto el identificador como la dirección del acreedor garantizado pueden cambiar de resultas de una fusión de empresas o de otro cambio de nombre o dirección. Si bien el identificador del acreedor garantizado no debería ser un criterio general de búsqueda (véase el párrafo 36 *infra*), el registro debería permitir que se obtuviera información recurriendo al identificador del acreedor garantizado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 29). Esta característica del sistema registral permitiría modificar de manera eficiente la información del acreedor garantizado en todas las notificaciones relacionadas con él en particular mediante una simple modificación global. El sistema de registro podría admitir que su personal, por solicitud del acreedor garantizado, o este mismo directamente, pudiera hacer una modificación global (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 29). En cualquiera de los dos casos, para proteger al acreedor

garantizado de toda modificación potencialmente errónea o fraudulenta, el registro debería poder solicitar y verificar la identidad del solicitante de la inscripción que tratara de efectuar una modificación global. Una modificación de esa índole sería especialmente útil en determinados casos, por ejemplo, una fusión o un cambio del nombre del acreedor garantizado. En cualquier caso, el identificador del acreedor garantizado no debería ser un criterio general de búsqueda (véase el párr. 36 *infra*).

2. Cancelación voluntaria

23. Como en el caso de la modificación, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que el acreedor garantizado esté facultado para modificar o cancelar una notificación en cualquier momento y en la medida en que corresponda (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 73). Para hacerlo no se necesitaría la autorización del otorgante, ya que la cancelación no le afecta, o solo le puede afectar favorablemente. A diferencia de la modificación, la cancelación se efectúa inscribiendo la notificación correspondiente en el fichero del registro y retirando la información consignada en el fichero de dominio público. La información que se retira se archiva durante un período prolongado de manera que se pueda consultar (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párrs. 51 a 53, y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 19).

24. La única información que el solicitante de la inscripción debería hacer constar en el espacio previsto de la notificación de cancelación sería el número de inscripción asignado a la notificación inicial por el registro, que queda vinculado permanentemente a esa notificación y a toda otra notificación posterior (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 30). No es necesario que el identificador del otorgante se consigne en la notificación de cancelación, ya que el solicitante de la inscripción habrá obtenido acceso al registro (por ejemplo, con su identificación de usuario y código de acceso) y tendrá el número de inscripción correspondiente.

25. El reglamento debe prever que la notificación de cancelación presentada por uno de los acreedores identificados en ella no afecte a los derechos del otro acreedor garantizado, ya que esa notificación tiene el mismo efecto que una modificación en la que se suprime a uno o más acreedores garantizados. En ese caso, únicamente una cancelación efectuada por todos los acreedores garantizados da lugar a que la información consignada en la notificación inscrita se retire del fichero de dominio público del registro y se archive (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52, sección B, Terminología e interpretación).

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si la cuestión examinada en el párrafo 25 debería abordarse expresamente en las recomendaciones.]

3. Corrección de caducidad o cancelación errónea

26. Si un acreedor garantizado no prorroga la inscripción oportunamente o inscribe una cancelación por inadvertencia, podrá inscribir una nueva notificación inicial de su garantía real, restableciendo así la eficacia de esta frente a terceros. No obstante, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, la oponibilidad a terceros y la prelación de la garantía real rigen únicamente desde el momento en que se efectúa la nueva inscripción (véase la *Guía*

sobre las Operaciones Garantizadas, recomendación 47). El acreedor garantizado perderá su prelación con respecto a todos los reclamantes concurrentes, incluidos aquellos respecto de los cuales tenía prelación, con arreglo a la norma de que tiene prelación el primero en inscribirse, antes de la caducidad o cancelación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 96).

27. Algunos Estados aplican un criterio menos estricto. Se otorga al acreedor garantizado un breve período de gracia tras producirse la caducidad o cancelación para que renueve la inscripción de modo que se restablezca la oponibilidad a terceros y el orden de prelación de su garantía real a partir de la fecha de la inscripción inicial. Sin embargo, a efectos de proteger a los terceros que intervengan, el régimen de las operaciones garantizadas de los Estados que aplican ese criterio dispone que la garantía real no sea oponible o esté subordinada a reclamantes concurrentes que hayan adquirido derechos sobre los bienes gravados o adelantado fondos al otorgante después de la caducidad o cancelación y antes de la nueva inscripción.

4. Modificación o cancelación obligatorias

28. La posibilidad de que un otorgante obtenga financiación puede verse socavada por la existencia de una notificación inscrita que no refleje exactamente su relación financiera con la persona designada acreedor garantizado en la notificación. En consecuencia, el régimen de las operaciones garantizadas o el reglamento debe disponer que el solicitante de la inscripción esté obligado a inscribir una notificación de modificación o de cancelación cuando: a) el otorgante no haya autorizado la inscripción de la notificación inicial o de modificación en absoluto o con la descripción que allí figura; b) se haya retirado la autorización y no se haya concertado un acuerdo de garantía; c) se haya modificado el acuerdo de garantía y, debido a esa modificación, la información consignada en la notificación inscrita sea inexacta, o d) la garantía real relacionada con la notificación inscrita se haya extinguido de resultados del pago, o por alguna otra razón, y no exista compromiso alguno de conceder más crédito (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 31, apartado a), en el que se establece una norma de derecho sustantivo que no figuraba en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*).

29. En esas circunstancias, el régimen de las operaciones garantizadas o el reglamento debe disponer que, si el solicitante de la inscripción no cumple esa obligación por sí mismo, el acreedor garantizado esté obligado a inscribir una notificación de modificación o de cancelación poco después de recibir una solicitud por escrito del otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72, apartado a), y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 31, apartado c)). Si aún así no se obtuviera su cooperación, debería establecerse un procedimiento judicial o administrativo rápido y económico que permitiera al otorgante exigir la cancelación o la modificación de la notificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72, apartado b), y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 31, apartado e)).

30. Según la opción que elija el Estado promulgante para su régimen de las operaciones garantizadas o su reglamento, una modificación o cancelación obligatorias podría ser inscrita por el personal del registro o por un funcionario judicial o administrativo especialmente autorizado por el Estado promulgante. En cualquiera de los dos casos, puede ser necesario adjuntar a la notificación de

modificación o de cancelación presentada la orden judicial o administrativa correspondiente (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 31, apartado g)). Por una parte, eso garantizaría más transparencia y certeza, pero, por la otra, implantar esa función en el sistema de registro puede aumentar su costo.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que, según la decisión que adopte con respecto a la exigencia de adjuntar la orden a la notificación que figura entre corchetes en la recomendación 31, apartado g), es posible que haya que modificar el texto del párrafo 30.]

B. Recomendaciones 28 a 31

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las recomendaciones 28 a 31, reproducidas en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.5. Tal vez también desee tomar nota de que, por razones de economía, las recomendaciones no se han incluido en el presente documento, pero se incorporarán en el texto final.]

VI. Consultas

A. Observaciones generales

1. Criterios para efectuar la consulta

31. Como ya se ha indicado (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1, párrs. 56 a 59), en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que el registro de garantías reales sea de dominio público y que cualquier persona pueda hacer una consulta sin necesidad de dar una razón para justificarla (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 54, apartados f) y g), y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 4). Conforme a la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, para tener debidamente en cuenta la necesidad de proteger la privacidad, la inscripción debería hacerse con la autorización del otorgante y debería establecerse un procedimiento judicial o administrativo ágil que permitiera a los otorgantes cancelar o modificar en forma rápida y económica toda notificación no autorizada o errónea (véanse los párrs. 28 a 30 *supra*).

32. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* exige al registro que solicite la identidad del solicitante de la inscripción y deje constancia de ella como condición para poder efectuar la inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 55, apartado b)), pero no contiene una recomendación análoga con respecto a la persona que realiza la consulta. Esa diferencia obedece al hecho de que una inscripción no autorizada puede restar posibilidades de obtener crédito a la persona designada como otorgante en la notificación inscrita. Si se solicita y se hace constar la identidad del solicitante de la inscripción, esa persona sabrá a quién dirigirse para exigir la modificación o cancelación de una inscripción no autorizada. Habida cuenta de que al consultar el fichero del registro no se puede alterar ni cambiar la información que allí figura, no se plantea ningún problema de esa índole. En consecuencia, el registro no debería estar obligado a solicitar y hacer constar la identidad de la persona que lo consulta, salvo a efectos de cobrar derechos, si correspondiera (la base de datos del registro debería protegerse contra

la piratería de información sin comprometer las consultas legítimas). Así pues, debería poderse consultar el fichero del registro simplemente utilizando la forma prescrita para la búsqueda y pagando los derechos que fueran necesarios (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 7).

33. Como ya se explicó (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1, párrs. 38 a 40), conforme al criterio recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, la información que consta en el fichero del registro debe indizarse u organizarse de otra forma a fin de poder consultarla remitiéndose al identificador del otorgante, razón por la cual ese identificador es el principal criterio que han de aplicar las personas que consultan el registro para buscar y obtener la información. Sin embargo, solo se podrá confiar en la exactitud de esta si en la búsqueda se utilizó el identificador del otorgante correcto. En el reglamento debería aplicarse el mismo criterio (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 32, apartado a)).

34. El registro también debería admitir que se buscaran y obtuvieran notificaciones remitiéndose al número de inscripción único asignado por el registro a la notificación inicial, que queda permanentemente vinculado a esa notificación y a toda otra notificación conexa posterior (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 32, apartado b)). Si bien los números de inscripción en general no son útiles para los terceros como criterio de consulta (ya que los terceros no tendrán esa información), constituyen otra opción para los acreedores garantizados que desean obtener una inscripción de manera rápida y eficiente con objeto de hacer constar una modificación o cancelación.

35. Como ya se indicó (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.1, párr. 43), en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se examina la cuestión del empleo del número de serie del bien como criterio de consulta suplementario cuando se trata de bienes que tienen un alto valor de reventa y un número de serie único u otro identificador alfanumérico (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 34 a 36).

36. Como ya se mencionó (véase el párr. 22 *supra*), el acreedor garantizado, ya sea directamente o por conducto del personal del registro, debería poder modificar correctamente su identificador o su dirección en todas las inscripciones que le conciernan realizando una sola modificación global. No obstante, el identificador del acreedor garantizado no debería ser un criterio de consulta para el público en general. Ese identificador tiene una pertinencia limitada para los objetivos jurídicos del sistema de registro. Por otra parte, permitir la consulta pública puede frustrar las expectativas legítimas de los acreedores garantizados, por ejemplo, debido al peligro de que una entidad crediticia pueda realizar una búsqueda utilizando el identificador del acreedor garantizado para obtener las listas de clientes de sus competidores (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 81).

2. Resultado de la consulta

37. El resultado de la consulta debería ser, ya sea una indicación de que no se ha hallado ninguna inscripción que corresponda al criterio utilizado, o bien una lista de todas las inscripciones que correspondan a ese criterio, junto con todos los pormenores de la información tal como aparecen en el fichero del registro (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 33, apartado a)). Que el resultado

obtenido refleje la información que corresponda exactamente al criterio de consulta, o que también abarque las correspondencias aproximadas, dependerá del diseño del sistema de registro (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 33, apartado b)).

38. Si se decide aplicar una función de búsqueda que también revele las correspondencias aproximadas, y si la información consignada en las notificaciones se almacena en una base de datos electrónica, deberá programarse la lógica de búsqueda de manera que muestre todo dato que se aproxime al identificador del otorgante introducido por el autor de la consulta. En un sistema de esa índole cabrá considerar válida la inscripción de una notificación aunque su autor haya cometido un ligero error al introducir el identificador del otorgante correcto (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.3, párrs. 42 a 45). Eso se debe a que el autor de una consulta por el identificador del otorgante correcto de todos modos podrá encontrar la inscripción (con el error) y considerar probable que el otorgante cuyo identificador aparece en el resultado de la consulta como dato inexacto, pero aproximado, es, a pesar de ello, el otorgante buscado. Eso dependerá de los siguientes factores: a) que el autor de la consulta pueda identificar con facilidad al otorgante por algún otro dato suyo como la dirección, la fecha de nacimiento o el número de identificación; b) que la lista de datos casi idénticos no sea tan larga como para impedir que el autor de la consulta determine satisfactoriamente si el otorgante que le interesa figura en ella, y c) que las reglas para determinar las respuestas “aproximadas” sean lo bastante objetivas y claras como para que el autor de la consulta pueda fiarse del resultado obtenido.

39. La lógica de indización y búsqueda de identificadores de los otorgantes también puede programarse de manera que se haga caso omiso de los signos de puntuación, los caracteres especiales y las diferencias tipográficas, así como de toda palabra o abreviatura que no sirva para singularizar el identificador (entre otras cosas, los artículos de un nombre común o propio o el indicador de un tipo de empresa, por ejemplo, “compañía”, “sociedad”, “SRL” o “SA”). En esos casos, un error al consignar esa clase de datos no invalidará la inscripción, ya que esta podrá localizarse a pesar del error.

40. La lógica de la correspondencia exacta también da lugar a que los tribunales no se vean en la necesidad de determinar si el error en el identificador del otorgante es insignificante o no y si la notificación que contiene el identificador incorrecto constituye o no una correspondencia “suficientemente aproximada”. En otras palabras, el tribunal tendrá que determinar si la persona que efectuó la consulta debería haber examinado algunas de las correspondencias de la página 1 del resultado, o todas ellas, y si deberían haberse consultado las correspondencias de la página 2.

41. El reglamento también debería disponer que el registro expidiera un certificado de consulta por solicitud de la persona que la haga y previo pago del derecho pertinente, si corresponde. Ese certificado debería resultar admisible, en principio, como prueba ante el tribunal de que se ha inscrito o no una notificación en una fecha y a una hora determinadas. Todas esas cuestiones deberían abordarse en las normas sobre la inscripción (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 33, apartado c)). La cuestión de la admisibilidad del resultado de la consulta o del certificado como prueba ante el tribunal y de su eventual valor probatorio incumbe al derecho procesal del Estado promulgante.

B. Recomendaciones 32 y 33

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las recomendaciones 32 y 33, reproducidas en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.5. Tal vez también desee tomar nota de que, por razones de economía, las recomendaciones no se han incluido en el presente documento, pero se incorporarán en el texto final.]

VII. Derechos de inscripción y de consulta

A. Observaciones generales

42. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que no se cobren derechos de inscripción y de consulta con objeto de aumentar los ingresos, sino para sufragar los gastos de capital y de funcionamiento del registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 37, y recomendación 54, apartado i)). Por derechos de inscripción se entiende allí todo lo que se cobra al solicitante de la inscripción, independientemente del nombre que se le dé (por ejemplo, impuesto a las operaciones o derechos de inscripción) o de que se imponga en el reglamento o en un decreto separado. La razón para adoptar ese criterio es que los derechos e impuestos excesivos restarían muchos incentivos para utilizar el registro, lo que socavaría la eficacia general del régimen de las operaciones garantizadas del Estado promulgante. Sin embargo, para evaluar la cuantía de los ingresos necesarios a efectos de sufragar los gastos, se debe tener en cuenta la necesidad de financiar el funcionamiento del registro, lo que abarca: a) los sueldos del personal del registro; b) la reposición del equipo físico; c) la modernización de los programas informáticos; d) la capacitación permanente del personal, y e) actividades promocionales y de capacitación sobre el funcionamiento del registro destinadas a los usuarios.

43. En el reglamento del registro debería aplicarse el mismo criterio (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 34). El relativamente bajo costo inicial de un registro electrónico de garantías reales debería poder amortizarse gracias al pago de derechos en concepto de servicios en un plazo relativamente breve. Además, es posible mantener un bajo costo, especialmente si el fichero del registro está informatizado y se permiten las inscripciones y consultas electrónicas directas. Por otra parte, si el registro se elabora en colaboración con una empresa privada, puede suceder que esa entidad privada haga la inversión inicial de capital en la infraestructura y que pueda resarcirse de su inversión cobrando un porcentaje de los derechos pagados por los usuarios del registro una vez que este se halle en funcionamiento.

44. El Estado promulgante podría considerar una lista de opciones, desde cobrar derechos diferentes por inscripciones, consultas y certificados de consulta en papel hasta no cobrar derecho alguno. En algunos Estados en que el registro es establecido y administrado por el Estado, no se cobra derecho alguno por la inscripción ni por la consulta a fin de promover la inscripción de las operaciones financieras. Ese criterio fomenta la inscripción y la consulta incluso en relación con operaciones de poca cuantía y otras operaciones que de otra forma podrían concertarse sin garantías de

seguridad. Eso significaría, no obstante, que el registro se subsidiaría con dinero de los contribuyentes.

45. Como ya se ha indicado (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.2, párr. 18), el Estado promulgante puede considerar la posibilidad de cobrar derechos de inscripción por operación o conforme a una escala móvil relacionada con el plazo de vigencia de la inscripción (en los sistemas en que se permita a los autores de la inscripción determinar dicho plazo). Este último enfoque tiene la ventaja de disuadir al solicitante de la inscripción de elegir un plazo demasiado largo por un exceso de cautela. Independientemente del criterio que se aplique, los derechos no deberían guardar relación con el importe máximo especificado en caso de ejecución de la garantía (en los sistemas en que se exija incluir esa información), ya que eso disuadiría a las personas de realizar la inscripción.

46. El Estado promulgante también puede considerar la posibilidad de que los derechos se establezcan o bien en el reglamento, o bien en virtud de otro acto administrativo que pueda ser más fácil de revisar. Enumerar los derechos de inscripción en un acto administrativo tiene la ventaja de que otorga flexibilidad al registro para adecuarlos de manera que cubran los gastos de funcionamiento del sistema, especialmente cuando ya no sea necesario cobrar derechos para resarcirse del costo inicial de la inversión. No obstante, ese enfoque tiene la desventaja de permitir que el registro se aproveche de esa relativa facilidad para aumentar injustificadamente los derechos.

47. Además, el Estado promulgante puede considerar si, en un sistema híbrido, sería razonable cobrar más por tramitar notificaciones y solicitudes de consulta en papel, habida cuenta de que el personal del registro ha de encargarse de hacerlo. Eso también alentaría a los usuarios, con el tiempo, a recurrir a las funciones de inscripción y consulta electrónicas.

48. Por otra parte, el Estado promulgante puede considerar la posibilidad de disponer la concertación de acuerdos de apertura de cuentas con los usuarios a efectos de facilitar su acceso a los servicios del registro y el pago de derechos de inscripción por los usuarios frecuentes.

B. Recomendación 34

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la recomendación 34, reproducida en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.5. Tal vez también desee tomar nota de que, por razones de economía, las recomendaciones no se han incluido en el presente documento, pero se incorporarán en el texto final.]

(A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.5) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 22º período de sesiones

[Original: inglés]

ADICIÓN**Índice***Recomendaciones*

Anexo I. Terminología y recomendaciones	
Terminología	
Recomendaciones	
I. Registro y director del registro	1-3
II. Acceso a los servicios del registro	4-9
III. Inscripción registral	10-20
IV. Información de la inscripción registral	21-27
V. Información de modificación y cancelación	28-31
VI. Consultas	32-33
VII. Derechos	34

Anexo I**Terminología y recomendaciones****Terminología***

a) Por “dirección” se entenderá: i) una dirección física, con nombre y número de calle, ciudad, código postal y estado; ii) un número de apartado de correos, ciudad, código postal y estado; iii) una dirección electrónica; o iv) una dirección que equivalga a lo especificado en i), ii) o iii);

b) Por “modificación” se entenderá el acto agregar, suprimir o cambiar la información contenida en una notificación inscrita, [por el único y solo solicitante de la inscripción o, si hay más de un autor, algunos de ellos,] así como el efecto de ese acto;

* Sección B de la introducción de la *Guía de las Operaciones Garantizadas*, relativa a la terminología e interpretación, se aplica también al proyecto de guía sobre el registro, complementada por la sección sobre terminología e interpretación de la introducción al proyecto de guía sobre el registro.

- c) Por “cancelación” se entenderá el acto de suprimir toda la información contenida en una notificación escrita [por el único y solo autor de la inscripción o, si hay más de un autor, por todos ellos];
- d) Por “otorgante” se entenderá la persona identificada en la notificación como otorgante;
- e) Por “ley” se entenderá la ley que rige las garantías reales sobre bienes muebles;
- f) Por “notificación” se entenderá toda comunicación escrita (consignada en papel o electrónica) que incluya una notificación inicial, una notificación de modificación o una notificación de cancelación¹;
- g) Por “solicitante de la inscripción” se entenderá la persona identificada en la notificación como el acreedor garantizado;
- h) Por “director del registro” se entenderá la persona nombrada con arreglo a la ley y el reglamento para que supervise y administre el funcionamiento del registro;
- i) Por “inscripción” se entenderá la incorporación en la base de datos del registro de la información consignada en una notificación;
- j) Por “número de inscripción” se entenderá la cifra única asignada por el registro a una notificación inicial y permanentemente asociado a esa notificación [y toda notificación posterior conexa];
- k) Por “fichero del registro” se entenderá la información contenida en todas las notificaciones inscritas que se almacena electrónicamente en la base de datos del registro e incluye el fichero a disposición del público y los archivos;
- l) Por “reglamento” se entenderá el conjunto de reglas que ponen en práctica las disposiciones de la ley relativa al registro.

Recomendaciones

I. Registro y director del registro

Recomendación 1: El registro

El reglamento debería disponer que el registro se establecerá con el fin de recibir, almacenar y hacer accesible al público la información relativa a las garantías reales sobre bienes muebles.

Recomendación 2: Nombramiento del director del registro

El reglamento debería disponer que [la identidad o la persona determinada por el Estado promulgante o autorizada por la ley del Estado promulgante] designará al director del registro, especificará las funciones del director del registro y supervisará el desempeño del director del registro.

¹ Véase el término “notificación” en la Introducción, sección B, Terminología e Interpretación, de la *Guía sobre Operaciones Garantizadas*.

Recomendación 3: Funciones del registro

El reglamento debería disponer que el registro cumplirá, entre otras, las funciones siguientes:

- a) Proporcionará acceso a sus servicios, de conformidad con las recomendaciones 4, 6, 7 y 8;
- b) Publicará los medios de acceso al registro y los días y horas de apertura, de conformidad con la recomendación 5;
- c) Hará saber los motivos del rechazo de una inscripción o una solicitud de consulta, de conformidad con la recomendación 9;
- d) Incorporará en la base de datos del registro la información contenida en una notificación, asignará un número de registro a la notificación inicial y registrará la fecha y hora de cada inscripción, de conformidad con la recomendación 10;
- e) Indexará u organizará de alguna otra manera la información consignada en el archivo del registro con el fin de que pueda ser consultada, de conformidad con la recomendación 14;
- f) Proporcionará a cada autor de una inscripción una copia de la notificación, de conformidad con la recomendación 16;
- g) Incorporará la información contenida en una notificación de modificación en la base de datos del registro, de conformidad con la recomendación 17;
- h) Retirá la información contenida en una notificación inscrita del [fichero del registro accesible al público] cuando expire su período de vigencia o la inscripción de una notificación de cancelación, de conformidad con la recomendación 18, y
- i) Archivará la información retirada del archivo del registro accesible al público de conformidad con la recomendación 19.

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si las remisiones a las recomendaciones pertinentes son necesarias en la recomendación 3. Por una parte, esas remisiones pueden ser útiles para el lector. Por otra, el propósito de la recomendación 3 tal vez no sea hacer las veces de una lista del contenido del reglamento sino servir de resumen de las funciones del registro, en cuyo caso las remisiones cruzadas posiblemente no sean necesarias.]

II. Acceso a los servicios del registro**Recomendación 4: Acceso del público a los servicios del registro**

El reglamento debería disponer que toda persona tenga derecho a acceder a los servicios que presta el registro.

Recomendación 5: Días y horas de funcionamiento del registro

El reglamento debería disponer que:

- a) Si el acceso a los servicios del registro se ofrece a través de una oficina física:
 - i) Cada oficina del registro debería estar abierta al público durante los días y horas [que especifique el Estado promulgante]; y
 - ii) La información acerca de la ubicación de las oficinas del registro y los respectivos días y horas de atención al público se publicarán ampliamente en el sitio web del registro, si lo hubiere, o de alguna otra manera, y los días y horas de apertura de cada oficina se anunciarán visiblemente en ella;
- b) Si el acceso a los servicios del registro se ofrece a través de medios de comunicación electrónicos, el acceso a los servicios que presta el registro deberá estar disponible en todo momento; y
- c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b) de esta recomendación:
 - i) El registro podrá suspender total o parcialmente el acceso a los servicios que presta; y
 - ii) La notificación de la suspensión de los servicios y su duración prevista se publicarán con antelación, cuando sea factible y, de no serlo, lo más pronto que sea razonablemente posible en el sitio web del registro, si lo hubiere, o de alguna otra manera, y, si el registro facilita el acceso a sus servicios a través sus oficinas físicas, las notificaciones deberán colocarse visiblemente en cada oficina.

Recomendación 6: Acceso a los servicios de inscripción registral

El reglamento debería disponer que toda persona tiene derecho a inscribir una notificación siempre que esa persona:

- a) Utilice el formulario de notificación que prescriba el registro;
- b) Acredite su identidad en la manera prescrita por el registro; y
- c) Haya abonado, o haya tomado disposiciones para abonar, todos los derechos que prescriba el registro.

Recomendación 7: Acceso a los servicios de consulta

El Reglamento debería disponer que toda persona tendrá derecho a consultar el fichero de registro accesible al público, siempre que utilice el formulario prescrito por el registro para las consultas y haya abonado, o haya tomado disposiciones para abonar, todos los derechos que prescriba el registro.

Recomendación 8: No se exige la verificación de la identidad ni prueba de la existencia de un poder ni el examen a fondo del contenido de la notificación

El reglamento debería disponer que:

- a) El registro exija y anote la identidad del solicitante de la inscripción pero no exija la verificación de su identidad;

b) El registro no exija prueba de la existencia de un poder para inscribir la notificación; y

c) El registro no examine a fondo el contenido de la notificación. En particular, no será responsable de velar por que la información de una notificación se consigne en el espacio previsto y sea completa, precisa y jurídicamente suficiente.

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que, como cuestión de redacción, la antigua recomendación 19 (A/CN.9/WG.VI/WP.50/Add.1) ha sido fusionada con la recomendación 8 ya que, al parecer, esas recomendaciones tratan de la misma cuestión. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si la nueva recomendación 8 se debe mantener en su forma actual. El Grupo de Trabajo tal vez desee también considerar si la segunda oración del apartado c) (“En particular ... suficiente.”) se debe conservar en el apartado c) de esta recomendación o se debe trasladar al comentario.]

Recomendación 9: Rechazo de una solicitud de inscripción o de consulta

El reglamento debería disponer que:

a) La inscripción de una notificación podrá ser rechazada si la notificación no proporciona, de manera legible, la información exigida por la recomendación 21, en el caso de una notificación inicial, la recomendación 28, en el caso de una notificación de modificación, o la recomendación 30, en el caso de una notificación de cancelación;

b) Una solicitud de consulta podrá ser rechazada si no suministra de manera legible un criterio de búsqueda según lo exigido por la recomendación 32; y

c) El registro deberá dar los motivos del rechazo de una notificación o solicitud de consulta de inmediato o tan pronto como sea factible.

III. Inscripción registral

Recomendación 10: Momento de validez de una notificación inscrita

El reglamento debería disponer que:

a) La inscripción de una notificación sea válida a partir de la fecha y hora en que la información consignada en la notificación se incorpore al fichero del registro de modo que quede disponible para quienes consulten el fichero accesible al público;

b) El registro mantenga una constancia de la fecha y hora en que cada notificación se incorpora en la base de datos del registro de modo que quede a disposición de quienes consulten el fichero accesible al público, y asigne a toda notificación inicial un número de inscripción, mediante el cual se identificarán la notificación inicial y cualquier otra notificación posterior; y

c) El registro incorpore en la base de datos y los índices del fichero, u organice de otra manera, la información consignada en una notificación inscrita de modo que quede a disposición, en el orden que se recibió, de quienes consulten el

fichero del registro accesible al público de inmediato o dentro de [un breve período que deberá especificar el Estado promulgante].

Recomendación 11: Período de validez de la inscripción registral

El reglamento debería disponer que:

Opción A

a) Toda inscripción registral será válida durante [el Estado promulgante deberá insertar el plazo especificado en su ley];

b) El período de vigencia de una inscripción registral se podrá prorrogar, en cualquier momento antes de que expire, por un plazo adicional igual al período inicial establecido en la ley. El nuevo período comienza en el momento en que expire el período en curso.

Opción B

a) Toda inscripción registral será válida durante el período indicado en la notificación inicial;

b) El período de vigencia de la inscripción registral se podrá prorrogar o acortar, en cualquier momento antes de que expire, por el período indicado en una notificación de modificación. En el caso de una prórroga, el nuevo período comienza en el momento en que expire el período en curso.

Opción C

a) Toda inscripción registral será válida durante el período indicado en la notificación inicial, que no será superior a [un período, como, por ejemplo, 20 años, que deberá especificar el Estado promulgante];

b) El período de vigencia de una inscripción registral se podrá prorrogar o acortar por el plazo indicado en una notificación de modificación, que no sea superior a [un plazo, como, por ejemplo, 20 años, que deberá especificar el Estado promulgante], en cualquier momento antes de que expire el período de vigencia de la inscripción registral. En el caso de una prórroga, el nuevo período se inicia en el momento en que expire el período en curso.

Recomendación 12: Momento en el que podrá inscribirse una notificación

El reglamento debería disponer que toda notificación pueda inscribirse antes o después de que se constituya la garantía real o de que se celebre el acuerdo de garantía pertinente.

Recomendación 13: Suficiencia de una notificación única

El reglamento debería disponer que la inscripción de una sola notificación bastará para dotar de eficacia frente a terceros a una o más garantías reales sobre el bien descrito en la notificación, tanto si están constituidas en el momento de la inscripción como si se constituyen ulteriormente, o si nacen de uno o más acuerdos de garantía concertados entre las mismas partes.

Recomendación 14: Indización u otra organización de la información en el fichero del registro

El reglamento debería disponer que:

- a) El registro indizará u organizará de otra manera la información del fichero del registro consignada en una notificación inicial en el fichero del registro a disposición del público de forma que se pueda consultar por medio del identificador del otorgante;
- b) El registro indizará u organizará de otra manera la información del fichero del registro consignada en una notificación de modificación en el fichero del registro a disposición del público de modo que se pueda consultar junto con la notificación inicial; y
- c) El registro indizará u organizará de alguna otra manera la información consignada en una notificación de cancelación en los archivos del registro de modo que pueda ser recuperada, conforme a la recomendación 19, junto con la notificación inicial en su forma enmendada.

Recomendación 15: Integridad del fichero del registro

El reglamento debería disponer que, salvo lo previsto en las recomendaciones 17 y 18, el registro no modificará la información consignada en el fichero del registro ni retirará información de él.

Recomendación 16: Copia de la notificación inscrita

El reglamento debería disponer que:

- a) El registro deberá remitir prontamente una copia de la notificación inscrita a cada autor de una inscripción a la dirección consignada en la notificación, indicando la fecha y hora en que pasó a ser oponible y el número de inscripción; y
- b) El solicitante de la inscripción deberá enviar una copia de una notificación registrada a cada otorgante a la dirección consignada en la notificación o a la dirección actual que conozca el solicitante de la inscripción en [un breve plazo, por ejemplo 30 días, que deberá especificar el Estado promulgante] después de que el solicitante de la inscripción haya recibido copia de la notificación inscrita.

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que, como cuestión de redacción, la antigua recomendación 31 (A/CN.9/WG.VI/WP.50/Add.2) ha sido puesta inmediatamente después de la recomendación 15, ya que la Guía sobre las Operaciones Garantizadas trata la cuestión de la copia de las notificaciones inscritas como un asunto de integridad del fichero del registro. En todo caso, la copia de las notificaciones inscritas no es una cuestión que deba ir en una sección relativa a la cancelación y la modificación, a menos que se refiera solo a una copia de una notificación de modificación o cancelación, aunque, incluso en ese caso, se trata de una cuestión que se relaciona más con la integridad del fichero del registro. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si la nueva recomendación 16 debe mantenerse en este lugar del texto.]

Recomendación 17: Modificación de la información consignada en el fichero del registro

El reglamento debería disponer que la información consignada en una notificación inscrita solo podrá ser enmendada mediante la inscripción de una notificación de modificación, conforme a las recomendaciones 28, 29 o 31.

Recomendación 18: Retirada de información del fichero del registro

El reglamento debería disponer que la información consignada en una notificación inscrita se retire del fichero del registro a disposición del público cuando expire su período de vigencia o cuando se inscriba una notificación de cancelación, de conformidad con las recomendaciones 30 o 31.

Recomendación 19: Archivo de la información retirada del fichero del registro

El reglamento debería disponer que la información retirada del fichero del registro a disposición del público se archive durante un período mínimo de [un período prolongado, como, por ejemplo, 20 años, que deberá especificar el Estado promulgante] que permita que la información se pueda recuperar.

Recomendación 20: Idioma de la notificación

El reglamento debería disponer que la información de una notificación se expresará en [el idioma o idiomas que habrá de especificar el Estado promulgante]. El registro deberá especificar y dará a conocer públicamente el conjunto de caracteres que se habrá de utilizar.

IV. Información de la inscripción registral

Recomendación 21: Información que ha de consignarse en una notificación inicial

El reglamento debería disponer que:

- a) La notificación inicial deberá contener la información siguiente en el espacio previsto:
 - i) El identificador y la dirección del otorgante, de conformidad con las recomendaciones 22 a 24;
 - ii) El identificador y la dirección del acreedor garantizado o su representante, de conformidad con la recomendación 25;
 - iii) Una descripción de los bienes gravados, de conformidad con las recomendaciones 26 y 27;
 - [iv) El plazo de vigencia de la inscripción, conforme a la recomendación 11²; y
 - v) El importe monetario máximo por el que se podrá ejecutar la garantía real]³; y

² En caso de que el Estado promulgante haya elegido la opción B o C en la recomendación 11 (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación. 69).

³ En caso de que lo requiera la ley de operaciones garantizadas del Estado promulgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación. 57, apartado d)).

b) Si hay más de un otorgante o acreedor garantizado, el solicitante de la inscripción deberá presentar la información exigida por separado respecto de cada otorgante o acreedor garantizado, en el espacio previsto de la misma notificación o de notificaciones diferentes.

Recomendación 22: Identificador del otorgante (persona física)

El reglamento debería disponer que, si el otorgante es una persona física:

a) El identificador del otorgante será:

Opción A

El nombre del otorgante

Opción B

El nombre del otorgante y [cualquier otra información especificada por el Estado promulgante para identificar inequívocamente al otorgante, como la fecha de nacimiento o cualquier otra identificación personal u otro número asignado al otorgante por el Estado promulgante];

b) Cuando el nombre del otorgante consista en el apellido y uno o más nombres de pila, el nombre del otorgante constará del apellido y los nombres de pila primero y segundo, y cada componente del nombre deberá consignarse en el espacio previsto;

c) Cuando el nombre del otorgante consista en una sola palabra, el nombre del otorgante consistirá en esa palabra y deberá consignarse en el espacio previsto para el apellido;

d) el nombre del otorgante se determinará de la siguiente manera:

i) Si el otorgante nació en [el Estado promulgante] y su nacimiento está registrado en él en una entidad estatal encargada del registro de nacimientos, el nombre del otorgante será el nombre que figure en la partida de nacimiento del otorgante o en el documento equivalente expedido por esa entidad estatal;

ii) Si el otorgante nació en [el Estado promulgante] pero su nacimiento no está registrado en él, el nombre del otorgante será el que figure en el pasaporte vigente que le haya expedido [el Estado promulgante];

iii) Si ninguno de los criterios indicados en los apartados i) o ii) del párrafo d) de esta recomendación es aplicable, el nombre del otorgante será el que figure en [el Estado promulgante deberá especificar el tipo de documento oficial, por ejemplo una tarjeta de identificación o una licencia de conducción, expedido al otorgante por el Estado promulgante que este considere apropiado];

iv) Si ninguno de los criterios indicados en los apartados i), ii) o iii) del párrafo d) de esta recomendación es aplicable pero el otorgante es ciudadano de [el Estado promulgante], el nombre del otorgante será el nombre que figure en el certificado que acredite su nacionalidad;

v) si ninguno de los criterios indicados en los apartados i), ii), iii), o iv) del párrafo d) de esta recomendación es aplicable, el nombre del otorgante será el

nombre que figure en un pasaporte válido que le haya expedido el Estado del cual el otorgante sea ciudadano, y si el otorgante no posee un pasaporte válido, su nombre será el nombre que figure en la partida de nacimiento o documento equivalente que le haya expedido el organismo estatal encargado del registro de nacimientos en el lugar en que nació el otorgante;

vi) En todo supuesto que no esté comprendido en los apartados i) a v) del párrafo d) de esta recomendación, el nombre del otorgante será el nombre que figure en dos documentales oficiales válidos cualesquiera [el Estado promulgante deberá especificar los documentos distintos de los indicados en el apartado iii) del párrafo d) de esta recomendación, como la tarjeta de la seguridad social, del seguro de salud o de impuestos, expedida al otorgante por el Estado promulgante].

Recomendación 23: Identificador del otorgante (personal jurídica)

El reglamento debería disponer que, si el otorgante es una persona jurídica, el identificador del otorgante será

Opción A

El nombre del otorgante que se indique como su nombre en [el documento, la ley o el decreto especificado por el Estado promulgante] más reciente por el [la] que se constituya dicha persona jurídica.

Opción B

El nombre del otorgante que se indique como su nombre en [el documento, la ley o el decreto especificado por el Estado promulgante] más reciente por el [la] que se constituya dicha persona jurídica, y [otro identificador especificado por el Estado promulgante para identificar inequívocamente al otorgante, como un registro u otro número].

[Recomendación 24: Identificador del otorgante (casos especiales)]

El reglamento debería disponer que:

a) Si los bienes gravados están sujetos a un procedimiento de insolvencia, el identificador del otorgante será el nombre de la persona insolvente, de conformidad con la recomendación 22 o 23, con la aclaración, en un espacio separado, de que el otorgante se encuentra en procedimiento de insolvencia;

b) Si el otorgante es un consorcio o una empresa conjunta, el identificador del otorgante será el nombre del consorcio o la empresa conjunta según conste en [el documento, la ley o el decreto especificado por el Estado promulgante] más reciente por el [la] que se constituye el consorcio o empresa [y toda información adicional especificada por el Estado promulgante para identificar inequívocamente al otorgante], de conformidad con la recomendación 22 o 23;

c) [Si el otorgante es una sociedad fiduciaria o un patrimonio, el identificador del otorgante será el nombre de la sociedad fiduciaria o el patrimonio de conformidad con la recomendación 22 o 23, con la aclaración, en un espacio separado, de que el otorgante es una sociedad fiduciaria o un patrimonio.]

d) Si el otorgante es una entidad distinta de algunas de las ya mencionadas en las reglas precedentes, el identificador del otorgante será el nombre de la entidad que se indique en [el documento, la ley o el decreto especificado por el Estado promulgante] más reciente por el [la] que se constituya dicha entidad [y toda información adicional especificada por el Estado promulgante para identificar inequívocamente al otorgante] de conformidad con la recomendación 22 o 23.

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que, con arreglo a su decisión (véase A/CN.9/743, párr. 47), la recomendación 24 figura entre corchetes para indicar que su finalidad es exponer ejemplos de casos especiales para que los Estados promulgantes procedan a una selección y los adapten a sus propias leyes, dado que los casos se tratan de modo diferente de un Estado a otro.]

Recomendación 25: Identificador del acreedor garantizado

El reglamento debería disponer que:

- a) Si el acreedor garantizado o su representante es una persona natural, el identificador será el nombre del acreedor garantizado o su representante, de conformidad con la recomendación 22;
- b) Si el acreedor garantizado o su representante es una persona jurídica, el identificador será el nombre del acreedor garantizado o su representante, de conformidad con la recomendación 23; y
- c) Si el acreedor garantizado o su representante es una persona del tipo indicado en la recomendación 24, el identificador será el nombre de la persona, de conformidad con la recomendación 24.

Recomendación 26: Descripción de los bienes gravados

El reglamento debería disponer que:

- a) Cuando los bienes gravados estén descritos en una notificación inicial o de modificación, deberán describirse en el espacio previsto de la notificación de una manera que permita razonablemente identificarlos;
- b) A menos que la ley disponga otra cosa, una descripción genérica que remita al conjunto de bienes de una determinada categoría de bienes muebles incluirá todos los bienes actuales y futuros del otorgante pertenecientes a la categoría especificada; y
- c) A menos que la ley disponga otra cosa, una descripción genérica que remite a los bienes muebles del otorgante incluirá todos los bienes muebles actuales y futuros del otorgante.

Recomendación 27: Información incorrecta o insuficiente

El reglamento debería disponer que:

- a) Una notificación inicial o una notificación de modificación que modifique el identificador del otorgante o agregue un otorgante, solo surtirá efecto si facilita el identificador correcto del otorgante, según lo dispuesto en las recomendaciones 22 a 24, o, de haberse indicado un identificador incorrecto, si es

posible recuperar la notificación mediante una búsqueda en el fichero del registro a partir del identificador correcto;

b) Salvo lo previsto en el apartado a) de esta recomendación, una declaración incorrecta o insuficiente de la información que ha de suministrarse en una notificación inscrita no privará de validez a esa inscripción, a menos que induzca a error grave al autor razonable de una consulta;

c) Un identificador incorrecto de un otorgante en una notificación inscrita no la privará de validez con respecto a otros otorgantes suficientemente identificados en la notificación;

d) Una descripción insuficiente de los bienes gravados en una notificación inscrita no la privará de validez con respecto a otros bienes gravados suficientemente descritos en la notificación [; y

e) Una declaración incorrecta en la notificación inscrita con respecto al período de vigencia de la inscripción y el monto máximo asegurado no privará de validez a la notificación, si bien deberán quedar protegidos terceros que se hayan basado en esa declaración incorrecta].

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si se debería mantener el apartado e) de la presente recomendación, que ha sido agregado para reflejar el principio consagrado en la recomendación 66 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas.]

V. Información de modificación y cancelación

Recomendación 28: Información que deberá contener una notificación de modificación

El reglamento debería disponer que:

a) En una notificación de modificación se deberá consignar, en el espacio previsto, la información siguiente:

i) El número de inscripción de la notificación inscrita a que se refiere la modificación;

ii) Si se desea agregar información, se deberá indicar la información adicional conforme a lo prescrito por el reglamento para la introducción de información de esa índole; y

iii) Si se desea modificar información, la nueva información conforme a lo prescrito en el reglamento para la introducción de información de esa índole;

[b) Una notificación de modificación que revele una transmisión de los bienes gravados deberá agregar el identificador y la dirección del beneficiario de la transmisión como otorgante, de conformidad con las recomendaciones 22 a 24. Una modificación que revele una transmisión que afecte únicamente a una parte de los bienes gravados, deberá indicar el identificador y la dirección del beneficiario como otorgante, de conformidad con las recomendaciones 22 a 24, y transcribir la parte de los bienes gravados transmitidos, de conformidad con la recomendación 26;]

c) Una notificación de modificación que revele una cesión de la obligación garantizada deberá indicar el identificador y la dirección del cesionario como acreedor garantizado, de conformidad con la recomendación 25, y, en el caso de una cesión parcial, indicar los bienes gravados a los que se refiere la cesión parcial en el espacio previsto; y

d) Una notificación de modificación puede referirse a

Opción A

Un solo punto de la información consignada en una notificación.

Opción B

Un punto o puntos múltiples de la información consignada en una notificación.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si el cambio a que se refiere el apartado iii) de la recomendación 28 abarca la supresión de información o si debería incluirse un apartado separado para ocuparse de las supresiones. A ese respecto, el Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que los cambios y supresiones pueden tener consecuencias diferentes respecto de la oponibilidad frente a terceros.]

Recomendación 29: Modificación global única de la información relativa a un acreedor garantizado consignada en múltiples notificaciones

El reglamento debería disponer que el autor de una inscripción mencionado en múltiples notificaciones inscritas podrá modificar o pedir al registro que modifique mediante una única modificación global la información relativa al acreedor garantizado.

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si en la recomendación 29 se deberían ofrecer ambas opciones (una modificación efectuada por el solicitante de la inscripción y por el registro a solicitud del solicitante de la inscripción), o solo una de ellas, y, en tal caso, cuál. Se podría designar un registro para dar cabida a ambas opciones pero esa medida tendría algún costo.]

Recomendación 30: Información que deberá contener una notificación de cancelación

El reglamento debería disponer que en las notificaciones de cancelación conste, en el espacio previsto el número de inscripción

Recomendación 31: La modificación o cancelación obligatorias

El reglamento debería disponer que:

a) Todo autor de una inscripción estará obligado a inscribir una notificación de modificación o cancelación siempre que:

i) La inscripción de la notificación inicial o una modificación no haya sido autorizada por el otorgante en absoluto o en el grado descrito en la notificación;

- ii) La autorización haya sido retirada y no se haya concertado ningún acuerdo de garantía;
 - iii) El acuerdo de garantía haya sido revisado de manera que la información contenida en la notificación inscrita resulte inexacta; o
 - iv) La garantía real a que se refiere la inscripción inscrita se haya extinguido por pago o alguna otra razón y no haya obligación de conceder nuevo crédito;
- b) En el caso de los apartados ii) a iv) del párrafo a) de esta recomendación, el solicitante de la inscripción podrá cobrar los honorarios acordados con el otorgante;
- c) Todo autor de una inscripción estará obligado a presentar al registro una notificación de modificación o cancelación, según proceda, a más tardar [un plazo corto, por ejemplo, 15 días, que habrá de especificar el Estado promulgante] después de que el solicitante de la inscripción haya recibido una solicitud escrita del otorgante si se ha producido alguna de las circunstancias descritas en el apartado a) de esta recomendación y el solicitante de la inscripción no haya cumplido;
- d) El solicitante de la inscripción no podrá cobrar ni aceptar ningún honorario u otra suma de dinero por el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado c) de esta recomendación;
- e) Si el solicitante de la inscripción no cumple el plazo prescrito en el apartado c) de esta recomendación, el otorgante estará facultado para pedir la correspondiente cancelación o modificación por medio de un procedimiento judicial o administrativo sumario;
- f) El otorgante tendrá derecho a pedir una cancelación o modificación por medio de un procedimiento judicial o administrativo sumario aún antes de vencido el plazo previsto en el apartado c) de esta recomendación, siempre que se disponga de algún dispositivo adecuado para amparar al solicitante de la inscripción; y
- g) La notificación de modificación o cancelación sea efectuada por

Opción A

El registro, sin demora, al recibo de la notificación [adjuntando la correspondiente orden judicial o administrativa].

Opción B

Un funcionario judicial o administrativo, sin demora, al recibo de la notificación [adjuntando una copia de la correspondiente orden judicial o administrativa].

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota con respecto al apartado a) de que, si bien obligar al acreedor garantizado a que se asegure de que las inscripciones estén al día puede ser una buena política, la Guía sobre las Operaciones Garantizadas no formula ninguna recomendación sobre esta cuestión distinta de la que el acreedor garantizado deberá estar obligado a inscribir una notificación de modificación o cancelación únicamente a solicitud del otorgante. Sea como fuere, el Grupo de Trabajo tal vez desee tener presente de que esta es una cuestión de derechos sustantivo que debería abordarse en el comentario y no en las recomendaciones relativas a un reglamento del registro. Además, el

Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que los apartados b) y d) tratan cuestiones que se suelen abordar en el acuerdo de garantía y el derecho aplicable a las obligaciones. Por ello, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si esas cuestiones se deberían también examinar más bien en el comentario únicamente.]

VI. Consultas

Recomendación 32: Criterios de consulta

El reglamento debería disponer que el criterio aplicable para la realización de una consulta del fichero del registro accesible al público será:

- a) El identificador del otorgante; o bien
- b) El número de inscripción

Recomendación 33: Resultados de la consulta

El reglamento establece que:

- a) En el resultado de la consulta que suministre el registro se deberá indicar la fecha y hora en que se efectuó la consulta y o bien consignar toda la información de cada notificación inscrita que se ajuste al criterio de consulta especificado o indicar que ninguna notificación inscrita cumple el criterio de consulta;
- b) El resultado de una consulta revele información consignada en el fichero del registro que corresponda exactamente al criterio de búsqueda excepto [el Estado promulgante especificará las excepciones];
- c) A solicitud del autor de la consulta, el registro expedirá un certificado oficial de consulta en que se indique el resultado de la búsqueda.

VII. Derechos

Recomendación 34: Derechos por concepto de servicios del registro

El reglamento debería estipular que:

Opción A

- a) [A reserva de lo dispuesto en el apartado b) de esta recomendación,] se pagarán los siguientes derechos por concepto de servicios de registro:
 - i) Inscripciones:
 - a. En papel [...];
 - b. Electrónicas [...];
 - ii) Consultas:
 - a. En papel [...];
 - b. Electrónicas [...];

iii) Certificados:

- a. En papel [...];
- b. Electrónicos [...];

b) El registro podrá concertar un acuerdo con una persona que cumpla todas las condiciones del registro y crear una cuenta de usuario del registro que facilite el pago de derechos.

Opción B

[El Estado promulgante deberá especificar un organismo administrativo] podrá determinar por decreto los derechos y métodos de pago para los fines del presente reglamento.

Opción C

Los servicios [del registro] [de consulta] [de consulta electrónica] serán gratuitos.

(A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.6) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 22º período de sesiones

[Original: inglés]

ADICIÓN

ANEXO II. Ejemplos de formularios de registro**Adición**

El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar los ejemplos de formularios de registro que figuran en la presente nota. Los ejemplos se presentan como anexo II del proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, a continuación del anexo I, que versa sobre terminología y recomendaciones. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si habría que preparar otros ejemplos de formularios, tales como listas para asentar información suplementaria.

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES**EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN INICIAL****(FORMULARIO A)**

EL SOLICITANTE DE LA INSCRIPCIÓN SERÁ RESPONSABLE DE VELAR POR QUE SE APORTE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE CONSIGNE EN EL ESPACIO PREVISTO DE LA NOTIFICACIÓN EN FORMA LEGIBLE.

[..... (dd) (mm) (aaaa) (hora)* de inscripción de la notificación inicial y núm. de inscripción
- NO RELLENAR - DATOS GENERADOS POR EL SISTEMA DE REGISTRO]

A. INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGANTE**1. PERSONA FÍSICA**

...../...../.....
Apellido Primer nombre Segundo nombre

[INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE]¹.....

* En cifras.

¹ Nota al Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que este espacio se ha incluido para usarse en aquellos Estados que elijan la opción B de la recomendación 22, apartado a) del proyecto de guía sobre el registro, es decir, los Estados que opten por requerir o permitir la inscripción de información adicional sobre el identificador del otorgante como, por ejemplo, su fecha de nacimiento o un número de identificación u otro número asignado por el Estado a sus residentes o ciudadanos. Si bien en el formulario se debe precisar con exactitud el tipo de información adicional sobre el identificador que se debe o se puede indicar, ello

DIRECCIÓN
y/o dirección electrónica²

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

[INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE]

DIRECCIÓN
y/o dirección electrónica

3. SÍRVASE INDICAR SI EL OTORGANTE ES³

..... una persona insolvente

..... un consorcio o una empresa conjunta

..... una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre se ha dado

..... una entidad diferente de las arriba mencionadas

4. OTORGANTE ADICIONAL (si corresponde)

a) PERSONA FÍSICA

NOMBRE/...../.....
Apellido Primer nombre Segundo nombre

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN [si lo expide el Estado promulgante]

DIRECCIÓN
y/o dirección electrónica

b) PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

[INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE]

dependerá de lo que elija cada Estado promulgante.

² Nota al Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar cuál es el objetivo de indicar la dirección electrónica. Si se trata de ayudar a quien realice una búsqueda a distinguir entre varios otorgantes con el mismo nombre, por ejemplo, "Juan Pérez", la dirección de correo electrónico del otorgante no será de ayuda, dado que una persona puede tener varias direcciones de correo electrónico, e indicar una de ellas no ayudará necesariamente a quien haga una búsqueda a distinguir entre un Juan Pérez y otro. En cambio, si la intención es ofrecer un modo de que las partes interesadas se puedan poner en contacto con el otorgante, entonces indicar la dirección sí resultaría útil (véase la recomendación 54, apartado c), aunque de todos modos el solicitante de la inscripción debería disponer de la dirección de correo electrónico del otorgante). Con todo, la dirección de correo electrónico del otorgante se podría utilizar cuando un Estado exija que el registro comunique al otorgante que el acreedor garantizado ha efectuado cambios en la notificación inscrita.

³ Nota al Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee observar que esta parte refleja los casos especiales previstos en la recomendación 24.

DIRECCIÓN
y/o dirección electrónica

c) **INDIQUE SI EL OTORGANTE ES**

- una persona insolvente
..... un consorcio o una empresa conjunta
..... una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre se ha dado
..... una entidad diferente de las arriba mencionadas

B. INFORMACIÓN SOBRE EL ACREEDOR GARANTIZADO

1. PERSONA FÍSICA

...../...../...../
Apellido Primer nombre Segundo nombre

DIRECCIÓN
y/o dirección electrónica

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

DIRECCIÓN
y/o dirección electrónica

3. ACREEDOR GARANTIZADO ADICIONAL (si corresponde)

a) PERSONA FÍSICA

NOMBRE/...../...../
Apellido Primer nombre Segundo nombre

DIRECCIÓN
y/o dirección electrónica

b) PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

DIRECCIÓN
y/o dirección electrónica

C. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GRAVADOS

.....

[D. PERÍODO DE VALIDEZ DEL REGISTRO (dd) (mm) (aaaa)]⁴

[E. CUANTÍA MÁXIMA POR LA QUE ES EJECUTABLE LA GARANTÍA REAL]⁵

..... *

[F. INFORMACIÓN ADICIONAL].....

.....

[INFORMACIÓN SOBRE EL USUARIO DEL REGISTRO CON FINES DE ACCESO]

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES

EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

(FORMULARIO B)

EL SOLICITANTE DE LA INSCRIPCIÓN SERÁ RESPONSABLE DE VELAR POR QUE SE SUMINISTRE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE CONSIGNE EN EL ESPACIO PREVISTO DE LA NOTIFICACIÓN EN FORMA LEGIBLE.

ELIJA [UNA] [UNA O MÁS]⁶ DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

- Añadir o suprimir un otorgante o modificar/editar la información sobre el otorgante
- Añadir o suprimir un acreedor garantizado o modificar/editar la información sobre el acreedor garantizado
- Añadir o suprimir un bien gravado o modificar/editar la descripción de los bienes gravados (también para añadir o suprimir elementos o clases de bienes gravados y añadir una descripción de bienes que sean producto de los bienes gravados originales)
- Prorrogar el período de vigencia de la inscripción (cuando el Estado promulgante haya establecido un período de vigencia universal de la inscripción o un período máximo de la inscripción inicial)

⁴ Si el Estado promulgante ha elegido las opciones B o C de la recomendación 11 (véase *la Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 69).

⁵ Si así se exige en la ley de operaciones garantizadas del Estado promulgante (véase *la Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, apartado d)).

⁶ Nota al Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar cuál de las dos alternativas debería mantenerse (una sola modificación por notificación o bien varias modificaciones en una misma notificación). El Grupo de Trabajo quizá desee observar que, en cualquier caso, debería quedar claro que, si se produce primero una cesión de la obligación garantizada y se inscribe una notificación en la que se identifique al nuevo acreedor garantizado, y posteriormente se produce un cambio en los bienes gravados, solo el cesionario estará facultado para cambiar los bienes gravados.

- [Prorrogar o reducir el período de vigencia de la inscripción (cuando el Estado promulgante permita a los acreedores garantizados especificar el período de vigencia de la inscripción)]
- [Modificar la cuantía máxima por la que es ejecutable la garantía real (cuando el Estado promulgante lo permita)]
- Modificar la información sobre un acreedor garantizado en todas las notificaciones con una única modificación global
- Añadir, modificar o suprimir información con arreglo a una orden judicial o administrativa

[.....(dd) (mm) (aaaa) (hora)* de inscripción de la notificación de modificación
 - NO RELLENAR - DATOS GENERADOS POR EL SISTEMA DE REGISTRO]

A. NÚM. DE REGISTRO

B. AÑADIR UN OTORGANTE

1. PERSONA FÍSICA

...../...../...../
 Apellido Primer nombre Segundo nombre

[INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE]

DIRECCIÓN

y/o dirección electrónica

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

[INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE]

DIRECCIÓN

y/o dirección electrónica

3. SÍRVASE INDICAR SI EL OTORGANTE ES

..... una persona insolvente

..... un consorcio o una empresa conjunta

..... una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre se ha dado

..... una entidad diferente de las arriba mencionadas

* En cifras.

C. SUPRIMIR UN OTORGANTE**1. PERSONA FÍSICA**

...../...../...../
 Apellido Primer nombre Segundo nombre

[INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE]

DIRECCIÓN

y/o dirección electrónica

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

[INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE]

DIRECCIÓN

y/o dirección electrónica

3. SÍRVASE INDICAR SI EL OTORGANTE ES

..... una persona insolvente

..... un consorcio o una empresa conjunta

..... una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre se ha dado

..... una entidad diferente de las arriba mencionadas

D. MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGANTE**1. PERSONA FÍSICA**

...../...../...../
 Apellido Primer nombre Segundo nombre

[INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE]

DIRECCIÓN

y/o dirección electrónica

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

[INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE]

DIRECCIÓN

y/o dirección electrónica

3. SÍRVASE INDICAR SI EL OTORGANTE ES

- una persona insolvente
- un consorcio o una empresa conjunta
- una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre se ha dado
- una entidad diferente de las arriba mencionadas

E. AÑADIR UN ACREEDOR GARANTIZADO

1. PERSONA FÍSICA

...../...../...../

Apellido	Primer nombre	Segundo nombre
DIRECCIÓN		
y/o dirección electrónica		

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

DIRECCIÓN

y/o dirección electrónica

F. SUPRIMIR UN ACREEDOR GARANTIZADO

1. PERSONA FÍSICA

...../...../...../

Apellido	Primer nombre	Segundo nombre
DIRECCIÓN		
y/o dirección electrónica		

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

DIRECCIÓN

y/o dirección electrónica

G. MODIFICAR LA INFORMACIÓN SOBRE UN ACREEDOR GARANTIZADO

1. PERSONA FÍSICA

...../...../...../

Apellido	Primer nombre	Segundo nombre
DIRECCIÓN		
y/o dirección electrónica		

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE.....

DIRECCIÓN

y/o dirección electrónica

H. MODIFICAR LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GRAVADOS

.....

.....

I. PRORROGAR EL PERÍODO DE VALIDEZ DE LA INSCRIPCIÓN (cuando el Estado promulgante haya establecido un período de vigencia universal de la inscripción o un período máximo de la inscripción inicial..... (consigne el período de prórroga)*

[J. PRORROGAR O REDUCIR EL PERÍODO DE VALIDEZ DE LA INSCRIPCIÓN (cuando el Estado promulgante permita a los acreedores garantizados especificar el período de vigencia de la inscripción) _____ (dd) _____ (mm) _____ (aaaa)*]

[K. MODIFICAR LA CUANTÍA MÁXIMA POR LA QUE ES EJECUTABLE LA GARANTÍA REAL].....*

L. AÑADIR O SUPRIMIR INFORMACIÓN A PETICIÓN DEL OTORGANTE O CON ARREGLO A UNA ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA

.....

.....

.....

[INFORMACIÓN SOBRE EL USUARIO DEL REGISTRO CON FINES DE ACCESO]

[PERSONA QUE PRESENTA UNA NOTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN CON ARREGLO A UNA ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA]

NOMBRE DE LA PERSONA

CARGO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

y/o dirección electrónica

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES
EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN
(FORMULARIO C)

EL SOLICITANTE DE LA INSCRIPCIÓN SERÁ RESPONSABLE DE VELAR POR QUE SE APORTE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE CONSIGNE EN EL ESPACIO PREVISTO DE LA NOTIFICACIÓN EN FORMA LEGIBLE.

[.....(dd).....(mm).....(aaaa).....(hora)* de inscripción de la notificación de cancelación - NO RELLENAR - DATOS GENERADOS POR EL SISTEMA DE REGISTRO]

NÚM. DE REGISTRO.....

[INFORMACIÓN SOBRE EL USUARIO DEL REGISTRO CON FINES DE ACCESO]

[PERSONA QUE PRESENTA UNA NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN CON ARREGLO A UNA ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA]

NOMBRE DE LA PERSONA

CARGO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

y/o dirección electrónica

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES**EJEMPLO DE SOLICITUD DE CONSULTA****(FORMULARIO D)**

EL SOLICITANTE DE LA INSCRIPCIÓN SERÁ RESPONSABLE DE VELAR POR QUE SE SUMINISTRE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE CONSIGNE EN EL ESPACIO PREVISTO DE LA NOTIFICACIÓN EN FORMA LEGIBLE.

[.....(dd).....(mm).....(aaaa).....(hora)* de la solicitud de consulta - NO RELLENAR - DATOS GENERADOS POR EL SISTEMA DE REGISTRO]

[NÚM. DE REGISTRO.....]

A. INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGANTE**1. PERSONA FÍSICA**

...../...../...../
 Apellido Primer nombre Segundo nombre

[INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE]

.....

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE.....

[INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE]

.....

3. SÍRVASE INDICAR SI EL OTORGANTE ES

..... una persona insolvente

..... un consorcio o una empresa conjunta

..... una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre se ha dado

..... una entidad diferente de las arriba mencionadas

4. OTORGANTE ADICIONAL (si corresponde)**a) PERSONA FÍSICA**

...../...../...../
 Apellido Primer nombre Segundo nombre

[INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE]

.....

* En cifras.

b) PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE.....

[IDENTIFICADOR ADICIONAL DEL OTORGANTE].....

c) SÍRVASE INDICAR SI EL OTORGANTE ES

.....una persona insolvente

.....una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre
se ha dado

.....un consorcio o una empresa conjunta

.....una entidad diferente de las arriba mencionadas

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES**EJEMPLO DE RECHAZO DEL RESULTADO DE UNA CONSULTA****(FORMULARIO E)**[.....(dd).....(mm).....(aaaa).....(hora)* del resultado de la consulta - NO RELLENAR - DATOS
GENERADOS POR EL SISTEMA DE REGISTRO]**A. La consulta se realizó el (dd)/ (mm)/..... (aaaa)*.****B. Se encontraron las siguientes garantías reales:****C. No se encontraron garantías reales.**

* En cifras.

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES
EJEMPLO DE RECHAZO DE UNA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O DE CONSULTA
(FORMULARIO F)

A. Se rechaza la solicitud de inscripción porque:

1. En caso de una notificación inicial, no se ha consignado en forma legible en el espacio previsto:
 - a) El identificador y la dirección del otorgante,
 - b) El identificador y la dirección del acreedor garantizado o de su representante,
 - c) La descripción de los bienes gravados,
 - d) [El período de vigencia de la inscripción],
 - e) [El importe monetario máximo por el que se podrá ejecutar la garantía real].
2. En caso de una notificación de modificación, no se ha consignado en forma legible en el espacio previsto:
 - a) El número de inscripción de la notificación inscrita a la que se refiere la modificación,
 - b) Si se ha de agregar información, la información que habrá de agregarse,
 - c) Si se ha de modificar información, la información que habrá de modificarse.
3. En caso de una notificación de cancelación, no se ha consignado en forma legible en el espacio previsto el número de inscripción.

B. La solicitud de consulta se ha rechazado porque no se ha consignado en forma legible en el espacio previsto:

1. El identificador del otorgante.
2. El número de inscripción.

**C. Informe del Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales sobre
la labor realizada en su 23º período de sesiones
(Nueva York, 8 a 12 de abril de 2013)**

(A/CN.9/767)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-8
II. Organización del período de sesiones	9-14
III. Deliberaciones y decisiones	15
IV. Inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles	16-62
A. Prefacio (A/CN.9/WG.VI/WP.54)	16
B. Introducción (A/CN.9/WG.VI/WP.54 y A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrs. 1 a 23)	17-22
C. Creación y funciones del registro de garantías reales (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrs. 34 a 49)	23-25
D. Acceso a los servicios del registro (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrs. 50 a 65)	26-29
E. Inscripción registral (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 1 a 49)	30-37
F. Inscripción de notificaciones iniciales (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 50 a 71 y A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3, párrs. 1 a 35)	38-44
G. Inscripción de notificaciones de modificación y cancelación (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 1 a 41)	45-48
H. Criterio y resultados de la consulta (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 42 a 51)	49
I. Tasas de inscripción y de consulta (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 52 a 58)	50
J. Anexo I. Terminología y recomendaciones (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.5)	51
K. Anexo II. Ejemplos de formularios de registro (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.6)	52-61
L. Título del proyecto de guía para un registro	62
V. Proyecto de ley modelo sobre las operaciones garantizadas	63-64
VI. Labor futura	65-66

I. Introducción

1. En su período de sesiones actual, el Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) prosiguió su labor de preparación de un texto relativo a la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles, de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión en su 43º período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010)¹. La Comisión adoptó su decisión en el entendimiento de que ese texto sería un complemento útil de la labor de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas y ofrecería a los Estados una orientación urgentemente requerida para la apertura y el funcionamiento del registro general de las garantías reales².

2. En su 18º período de sesiones (Viena, 8 a 12 de noviembre de 2010) el Grupo de Trabajo inició su labor con el examen de una nota de la Secretaría titulada “Inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles” (A/CN.9/WG.VI/WP.44 y Add.1 y 2). En ese período de sesiones el Grupo de Trabajo adoptó la hipótesis de trabajo de que el texto revestiría la forma de una guía sobre la creación de un registro de las garantías reales, se ajustaría al contenido de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (la “*Guía sobre las Operaciones Garantizadas*”), y tendría en cuenta los enfoques seguidos en los sistemas modernos de inscripción registral de garantías reales, tanto nacionales como internacionales (A/CN.9/714, párr. 13). Tras convenir en que la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* era coherente con los principios rectores enunciados en los textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico, el Grupo de Trabajo estudió también ciertas cuestiones dimanantes del empleo de las comunicaciones electrónicas en los registros de las garantías reales con el fin de asegurar que, al igual que la *Guía*, el texto relativo a la inscripción registral también fuese coherente con esos principios (A/CN.9/714, párrs. 34 a 47).

3. En su 19º período de sesiones (Nueva York, 11 a 15 de abril de 2011) el Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía para un registro de las garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.46 y Add.1 a 3). En ese período de sesiones se expresaron opiniones divergentes sobre la forma y el contenido del texto que habría de prepararse (A/CN.9/719, párrs. 13 y 14), así como sobre la cuestión de si el texto debía presentarse en forma de reglamento modelo o de recomendaciones (A/CN.9/719, párr. 46).

4. En su 44º período de sesiones (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011), la Comisión insistió en la importancia de la labor del Grupo de Trabajo, habida cuenta en particular de los esfuerzos de los Estados por establecer un registro, así como de las posibles repercusiones beneficiosas que tendría el registro en la oferta y el precio del crédito. En cuanto a la forma y el contenido del texto que había de prepararse, la Comisión convino en que no era preciso modificar el mandato del Grupo de Trabajo, al que se confiaba la decisión sobre la forma y el contenido específicos del texto. Se convino además en que, en cualquier caso, la Comisión adoptaría la decisión final una vez que el Grupo de Trabajo hubiera concluido su labor y le hubiera presentado el texto³.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17* (A/65/17), párr. 268.

² *Ibid.*, párr. 265.

³ *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, *Suplemento núm. 17* (A/66/17), párr. 237.

5. En su 20º período de sesiones (Viena, 12 a 16 de diciembre de 2011), el Grupo de Trabajo prosiguió su labor basándose en una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía para un registro de las garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.48/Add.3). El Grupo de Trabajo convino en que el texto debía adoptar la forma de una guía (el “proyecto de guía para un registro”) con un comentario y recomendaciones similares a los de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (A/CN.9/740, párr. 18). Además, se convino en que cuando en el proyecto de guía se ofrecieran opciones, se podrían incluir en un anexo ejemplos de reglas modelo. En cuanto a la presentación del texto, se acordó que el proyecto de guía se presentara como un texto aparte, independiente y amplio que estuviera en consonancia con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y que se titulara provisionalmente “Guía legislativa técnica para la aplicación de un registro de las garantías reales” (A/CN.9/740, párr. 30).

6. En su 21º período de sesiones (Nueva York, 14 a 18 de mayo de 2012), el Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía legislativa técnica relativa a la aplicación de un registro de las garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.50 y Add.1 y 2). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección relativa a la terminología y de las recomendaciones del proyecto de guía (A/CN.9/743, párr. 21). Además, el Grupo de Trabajo acordó que el proyecto de guía se concluyera y se sometiera a la aprobación de la Comisión en su 46º período de sesiones, previsto para 2013 (A/CN.9/743, párr. 73). El Grupo de Trabajo convino también en proponer a la Comisión que le encomendara el mandato de elaborar una ley modelo sobre las operaciones garantizadas y que se mantuviera en su futuro programa de trabajo el tema de las garantías reales sobre valores no depositados en poder de intermediarios, a fin de examinarlo en un ulterior período de sesiones (A/CN.9/743, párr. 76).

7. En su 45º período de sesiones (Nueva York, 25 de junio a 6 de julio de 2012) la Comisión expresó su gratitud al Grupo de Trabajo y le pidió que agilizara y concluyera su labor, de modo que el proyecto de guía se pudiera presentar para darle su aprobación final y adoptarlo en su 46º período de sesiones, que se celebraría en 2013⁴. Además, la Comisión convino en que, una vez que el Grupo de Trabajo hubiese concluido el proyecto de guía, emprendería la preparación de una ley modelo sobre las operaciones garantizadas sencilla, breve y concisa, que se basara en las recomendaciones generales de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y se ajustara a todos los textos preparados por la CNUDMI en materia de operaciones garantizadas⁵. Asimismo, la Comisión acordó que, con arreglo a la decisión adoptada por ella en su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, se mantendría en el futuro programa de trabajo el tema de las garantías reales sobre valores no depositados en poder de intermediarios, entendidas como garantías distintas de las acreditadas en una cuenta de valores, a efectos de seguirlo examinando. Para ello, la Secretaría prepararía una nota en la que se enunciarían todas las cuestiones pertinentes, a fin de evitar duplicaciones o incoherencias con los textos preparados por otras organizaciones.

⁴ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 100.

⁵ *Ibid.*, párr. 105.

8. En su 22º período de sesiones (Viena, 10 a 14 de diciembre de 2012), el Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía legislativa técnica relativa a la aplicación de un registro de las garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.52 y Add.1 a 6). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del proyecto de guía para un registro y pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada del texto que reflejara las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/764, párr. 15).

II. Organización del período de sesiones

9. El Grupo de Trabajo, que se compone de todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 23º período de sesiones en Nueva York del 8 al 12 de abril de 2013. Asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Austria, Belarús, Benin, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, El Salvador, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, India, Italia, Japón, Kenya, México, Nigeria, Paraguay, Polonia, República de Corea, Tailandia, Turquía y Ucrania.

10. Asistieron al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Angola, Burkina Faso, Croacia, Guatemala, Indonesia, Kuwait, Qatar y Suiza. También asistieron al período de sesiones observadores de la Santa Sede.

11. Asistieron asimismo al período de sesiones observadores de las siguientes organizaciones internacionales:

- a) *Sistema de las Naciones Unidas*: Banco Mundial;
- b) *Organizaciones intergubernamentales*: Organización de los Estados Americanos (OEA);
- c) *Organizaciones no gubernamentales internacionales invitadas por la Comisión*: American Bar Association (ABA), Asociación Europea de Estudiantes de Derecho, Centro Nacional de Investigaciones Jurídicas para el Libre Comercio Interamericano, Commercial Finance Association (CFA), Federación Interamericana de Abogados (FIA), Inter-Pacific Bar Association (IPBA), International Insolvency Institute (III), Moot Alumni Association (MAA), New York City Bar (NYCBA) y Union Internationale des Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires (UIHJ).

12. El Grupo de Trabajo eligió la siguiente Mesa:

Presidente: Sr. Rodrigo LABARDINI FLORES (México)

Relator: Sr. Madhukar R. UMARJI (India)

13. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí los siguientes documentos: A/CN.9/WG.VI/WP.53 (Programa provisional anotado), A/CN.9/WG.VI/WP.54 y Add.1 a 6 (Proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de las garantías reales) y A/CN.9/WG.VI/WP.55 y Add.1 a 4 (Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas).

14. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:

- 1. Apertura del período de sesiones y programación de las reuniones.
- 2. Elección de la Mesa.

3. Aprobación del programa.
4. Inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles.
5. Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas.
6. Otros asuntos.
7. Aprobación del informe.

III. Deliberaciones y decisiones

15. El Grupo de Trabajo en primer lugar examinó una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de las garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.54 y Add.1 a 6), aprobó el proyecto de guía para un registro y lo remitió a la Comisión para su adopción en su 46º período de sesiones, cuya celebración está prevista del 8 al 26 de julio de 2013, en Viena. El Grupo de Trabajo examinó luego una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas” (A/CN.9/WG.VI/WP.55 y Add.1 a 4). Las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo se recogen más adelante en los capítulos IV a VI, respectivamente. Se pidió a la Secretaría que revisara el proyecto de guía para un registro y proyecto de ley modelo a fin de que reflejaran las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo.

IV. Inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles

A. Prefacio (A/CN.9/WG.VI/WP.54)

16. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido del prefacio del proyecto de guía para un registro en el entendimiento de que se actualizaría para reflejar los resultados del período de sesiones en curso y del período de sesiones de la Comisión.

B. Introducción (A/CN.9/WG.VI/WP.54 y A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrs. 1 a 23)

17. Con respecto a la sección A (Propósito del proyecto de guía sobre el registro y su relación con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*), se acordó lo siguiente: a) en el párrafo 3, se haría referencia a la inscripción como método para lograr la oponibilidad a terceros o, al menos, como método para determinar la prelación; b) en el párrafo 4, se haría referencia a otros textos sobre la inscripción, como los preparados por el Banco Mundial; y c) en el párrafo 6 e), se añadiría una referencia a los trabajos académicos.

18. Con respecto a la sección B (Terminología e interpretación), se acordó lo siguiente: a) se revisaría la explicación del significado de la palabra “modificación” para hacer referencia a “un cambio con respecto a la información ...”; b) se revisaría el párrafo 10 de forma que dijera algo como “la inscripción de una notificación de

modificación no da lugar a que se suprima o modifique la información contenida en una notificación inscrita con anterioridad a la que se refiera la notificación de modificación. La inscripción de una notificación de modificación tiene como consecuencia jurídica que se modifica la validez de la información a la que se refiere en la notificación inscrita con anterioridad en la medida del cambio que se especifique en la notificación de modificación. Conforme a la recomendación 11 la notificación de modificación es válida a partir del momento en que quede disponible para quienes efectúen consultas;” c) al final del párrafo 11, se añadiría una oración en términos como los siguientes, “Conforme a la recomendación 11, una notificación de cancelación es válida a partir del momento en que la notificación inscrita con anterioridad a la que se refiere la notificación de cancelación deja de ser accesible a las personas que consulten el fichero accesible al público”; d) la explicación del significado de la palabra “cancelación” haría referencia a “la retirada de toda la información” del fichero del registro accesible al público; e) en la explicación del significado de la expresión “solicitante de la inscripción”, se suprimiría el texto “y que puede ser un proveedor de servicios”, que figuraba entre corchetes; f) en la explicación del significado de la palabra “inscripción”, se suprimirían las palabras “la base de datos” y se mantendrían, sin corchetes, las palabras “el fichero”; g) en la explicación del significado de la expresión “fichero del registro”, se suprimirían las palabras “el fichero” y las palabras “la base de datos” y se haría referencia a “la información... *que almacena* el registro”; h) en la explicación del significado de la expresión “acreedor garantizado”, se suprimiría el texto que figuraba entre corchetes, que decía “y podrá ser el acreedor garantizado o su representante”; e i) se añadiría una explicación del significado de la palabra “registro” que diría algo como “un sistema para inscribir y consultar información relativa a las garantías reales sobre bienes muebles”.

19. Con respecto a la sección D (Información general sobre el régimen de las operaciones garantizadas y la función de la inscripción registral), se acordó lo siguiente: a) en la subsección D.2 (Concepto de la garantía real), se definiría la garantía real como un derecho de propiedad “limitado”; b) en la subsección D.4 (Oponibilidad a terceros de una garantía real), se incluiría en el párrafo 30 una referencia al párrafo 37 (relativo a la exclusión de las garantías del ámbito de aplicación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*), mientras que se suprimiría la nota a pie de página 9, relativa a la misma cuestión, y se incluiría una aclaración en el párrafo 31 para explicar que la inscripción en un registro especial sería un método alternativo para lograr la oponibilidad a terceros solo si no se dispone lo contrario en la legislación sobre propiedad intelectual; c) en la subsección D.5, a) a d), y en todo el texto del proyecto de guía para un registro, la Secretaría efectuaría los cambios editoriales necesarios para asegurar la coherencia en la redacción y evitar duplicaciones; d) en la subsección D.5 e), se explicaría que, aunque se optara por la inscripción de notificaciones relativas a créditos privilegiados, no se aplicará necesariamente la norma de la primera inscripción a efectos de la prelación; e) en la subsección D.6 (Amplio alcance operacional del registro), se revisaría el título de la subsección para que dijera algo como “Amplio alcance del registro”, dado que los créditos privilegiados (por ejemplo, las deudas fiscales) no siempre eran resultado de una operación, se añadiría el subtítulo “Créditos privilegiados” antes del párrafo 5, y se haría referencia en el párrafo al hecho de que en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* “se examinaba esa cuestión, pero no se hacía ninguna recomendación al respecto” (expresión que

debería utilizarse en todo el texto del proyecto de guía para un registro para referirse a tales casos) y se suprimiría la última oración del párrafo 5; f) en la subsección D.7 (Inscripción registral y ejecución de una garantía real), se haría referencia directamente a lo que se recomendaba en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*; y g) en la subsección D.9 (Inscripción registral de la notificación), por motivos de coherencia, se haría referencia al “otorgante” en lugar de al “deudor”.

20. También se convino en añadir al final de la sección D un párrafo relativo a la coordinación internacional entre los registros nacionales de garantías reales que dijera, por ejemplo, “Convendría que los Estados coordinaran y armonizaran en la mayor medida posible sus reglamentos y procedimientos relativos al registro a fin de reducir los costos que deben sufragar quienes efectúen inscripciones y consultas en el fichero del registro. Por tanto, sería aconsejable que los secretarios de los registros de los diferentes Estados se consultaran unos con otros y tuvieran en cuenta los reglamentos y procedimientos utilizados en los respectivos registros”.

21. Con respecto a la sección E (Problemas de la transición), se acordó lo siguiente: a) se suprimirían los párrafos 24 a 30; b) se colocarían los párrafos 31 y 32 al final de la sección D o en un lugar más apropiado; y c) se colocaría el párrafo 33 a continuación del párrafo 39, dado que hacía referencia a cuestiones relativas a aplicación adicionales.

22. Con sujeción a los cambios mencionados (véanse los párrs. 17 a 21 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó la Introducción.

C. Creación y funciones del registro de garantías reales (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrs. 34 a 49)

23. Con respecto a la subsección A.2 (Nombramiento del director del registro), se convino en aclarar que el secretario podría ser una persona jurídica o una persona física.

24. Con respecto a la recomendación 3, apartados d) y g), de conformidad con la correspondiente decisión sobre las expresiones “inscripción” y “fichero del registro” (véase el párr. 18 *supra*), se convino en hacer referencia al “fichero del registro” en lugar de a la “base de datos del registro”.

25. Con sujeción a los cambios que se mencionan *supra* (véanse los párrs. 23 y 24), el Grupo de Trabajo aprobó el capítulo I.

D. Acceso a los servicios del registro (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrs. 50 a 65)

26. Con respecto a la subsección A.3 (Acceso a los servicios de inscripción registral), se convino en suprimir la tercera oración del párrafo 56, dado que el otorgante se dirigiría al acreedor garantizado, no al solicitante de la inscripción, para exigir la modificación o cancelación de una inscripción no autorizada.

27. Con respecto a la subsección A.4 (No se exige la verificación de la identidad ni prueba de la existencia de una autorización ni el examen a fondo del contenido de la notificación), se acordó lo siguiente: a) los párrafos 59 a 61 se aplicarían a las notificaciones en general y no se limitarían necesariamente a las notificaciones iniciales; b) se incluirían referencias a la autorización por el otorgante, pues la autorización de las notificaciones de modificación o cancelación por el acreedor garantizado se trataba en otra parte del proyecto de guía para un registro (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 28 a 37); y c) se haría referencia al examen en el proyecto de guía para un registro de los tipos de modificación que exigían la autorización del otorgante, dado que no se requería esta autorización para todos los tipos de modificación (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párr. 3).

28. Con respecto a las recomendaciones 4 a 10, se acordó lo siguiente: a) en la recomendación 4, se mantendría sin corchetes el texto que figuraba entre corchetes; b) en la recomendación 6, se suprimiría el texto del encabezamiento que figuraba entre corchetes y se revisaría el apartado b) para que dijera, por ejemplo, “Se identifique de la manera prescrita por el registro”; c) en las recomendaciones 6 y 9, se añadiría un nuevo apartado para exigir que el registro proporcione los motivos para rechazar el acceso a los servicios de inscripción y de consulta, respectivamente; d) en la recomendación 7, se mantendría, sin corchetes, el texto del apartado a) que figura entre corchetes y, en el comentario correspondiente, se explicaría que el apartado b) se refiere a la autorización por el otorgante y se incluirá una remisión a la parte del proyecto de guía para un registro en que se examina la validez de las notificaciones de modificación y cancelación no autorizadas por el acreedor garantizado; e) en la recomendación 8, se revisaría el apartado a) para que dijera, por ejemplo, “El registro rechaza la inscripción de una notificación que se le presente para su inscripción si no se ha incorporado información en todos los espacios previstos de obligada cumplimentación ...”; f) en el comentario se explicaría la relación entre la recomendación 6, relativa al acceso a los servicios del registro, y la recomendación 8, relativa al rechazo de una notificación, y se examinarían las situaciones en que el registro podría tener que justificar los motivos para denegar el acceso a los servicios del registro (por ejemplo, en los casos en que la notificación se hubiera presentado por correo postal y el solicitante de la inscripción hubiera utilizado el formulario equivocado, o en que el documento de identidad estuviera caducado o se hubiera superado el límite de la tarjeta de crédito); y g) en la recomendación 10, se revisaría el apartado a) para que dijera, por ejemplo, “El registro rechaza ...”, y la Secretaría haría cambios editoriales similares en todo el texto del proyecto de guía para un registro para mantener la coherencia en la redacción.

29. Con sujeción a los cambios mencionados *supra* (véanse los párrs. 26 a 28), el Grupo de Trabajo aprobó el capítulo II.

E. Inscripción registral (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 1 a 49)

30. Con respecto a la subsección A.2 (Plazo de validez de la inscripción de una notificación), se convino en revisar la primera oración del párrafo 11 para que dijera, por ejemplo, “Si un Estado elige la variante A, no sería necesario concebir el sistema de registro de manera que permitiera al solicitante de la inscripción reducir el plazo legal de validez”.

31. Con respecto a la subsección A.3 (Momento en el que podrá inscribirse una notificación), se convino en que, cuando el proyecto de guía para un registro recomendara una norma que debiera figurar en el régimen legal de las operaciones garantizadas y que, según las prácticas legislativas del Estado promulgante, tal vez tuviera que incluirse o reiterarse en el reglamento sobre el registro, se haría referencia a la parte del proyecto de guía para un registro en que se trataran las cuestiones relacionadas con el método legislativo y la redacción (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párr. 32).

32. Con respecto a la subsección A.7 (Preservación de la integridad y seguridad del fichero del registro), se convino en lo siguiente: a) conforme a lo dispuesto en la recomendación 18, en el comentario se haría referencia a la obligación del registro de enviar copia de la notificación inscrita al acreedor garantizado, no al solicitante de la inscripción; y b) en el comentario se explicaría que el registro solo podría corregir los errores que se cometieran al inscribir en el fichero la información que figurase en una notificación en papel, pero no los errores que cometiera el solicitante de la inscripción.

33. Con respecto a la sección A.9 (Obligación del registro de enviar copia de una notificación inscrita a su autor), de conformidad con la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo en cuanto a la subsección A.7 (véase el párr. 32 *supra*), se convino en hacer referencia a la obligación del registro de enviar copia al acreedor garantizado, no al solicitante de la inscripción.

34. Con respecto a la subsección A.12 (Retirada y archivo de la información del fichero del registro accesible al público), se convino en hacer referencia a la recomendación 74 de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, según la cual la información debería archivarse tras la expiración o cancelación de una notificación, como se señala en la recomendaciones 69, 72 o 73, así como a la parte del proyecto de guía para un registro en que se examina la validez de las notificaciones de modificación y cancelación no autorizadas por el acreedor garantizado (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 28 a 37).

35. Con respecto a la subsección A.13 (Idioma de las notificaciones y las solicitudes de consulta), se convino en reformular el párrafo 49 para exponer la cuestión (múltiples versiones lingüísticas de un otorgante que sea una persona jurídica según el régimen conforme al cual se haya constituido) y ofrecer opciones a los Estados, señalando las correspondientes ventajas e inconvenientes. Se afirmó que una opción, por ejemplo, podría consistir en exigir que figurasen en la notificación todas las versiones lingüísticas del nombre del otorgante. Al respecto, se señaló que de esa forma se protegería a los terceros que consultaran el registro utilizando una de las versiones lingüísticas, pero se expondría al acreedor garantizado al riesgo de que se cometieran errores y de que la notificación no resultara válida. También se señaló que otra opción podría consistir en exigir que en la notificación figurase únicamente una de las versiones lingüísticas del nombre del otorgante. Se argumentó que de esa forma se protegería al acreedor garantizado contra el riesgo de que se cometieran errores y de que la notificación no resultara válida, pero se expondría a los terceros que consultaran el registro al riesgo de no encontrar la notificación inscrita si utilizaban otra versión lingüística del nombre del otorgante.

36. Con respecto a las recomendaciones 11 a 22, se convino en lo siguiente: a) de conformidad con la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo en cuanto a la terminología y la interpretación (véase el párr. 18 *supra*), en la recomendación 11 se haría referencia al “fichero del registro”, en lugar de a “la base de datos del registro”, y, dado que bastaba con emplear las palabras “lo antes posible”, se suprimirían del apartado c) las palabras “o dentro de [un breve plazo que deberá especificar el Estado promulgante]”; b) en la recomendación 11 habría que precisar las referencias a una “notificación” añadiendo las palabras “inicial o modificación”; c) en la recomendación 11, se añadirían los apartados d) y e) con un texto del siguiente tenor “d) La inscripción de una notificación de cancelación es válida a partir de la fecha y hora en que la notificación inscrita con anterioridad a la que se refiere deja de estar a disposición de las personas que consultan el registro accesible al público” y “e) El registro mantiene una constancia de la fecha y hora en que la notificación inscrita con anterioridad a la que se refiere la notificación de cancelación deja de estar a disposición de las personas que consultan el registro accesible al público”, y se prepararía un comentario para explicar los nuevos apartados referidos a una cuestión que no trata específicamente la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*; d) en la recomendación 12, se mantendría, sin corchetes, el texto que figuraba entre corchetes y se revisaría para que dijera, por ejemplo, “a todas las notificaciones relativas a una notificación inicial [se las identifique mediante] o [se las asocie con] el mismo número”; e) en todas las variantes de la recomendación 13, se suprimiría el apartado c) y se sustituiría con texto que se insertaría a continuación de la primera oración del apartado b) y que diría, por ejemplo, “mediante una notificación de modificación en la que se indique que el objeto de dicha modificación es prorrogar el plazo de vigencia”; f) en la recomendación 14, se suprimiría el texto entre corchetes; g) en la recomendación 16, se mantendría, sin corchetes, el texto que estaba entre corchetes; h) en la recomendación 18, apartado b), se dispondría que el acreedor garantizado “envíe” una copia de la notificación inicial a cada otorgante y se indicaría que la copia de la notificación inscrita mencionada al final de ese apartado era una copia transmitida por el registro al acreedor garantizado de conformidad con lo dispuesto en el apartado a), mientras que en el comentario se explicaría que, en el caso de que haya múltiples acreedores garantizados, bastará con que uno de ellos envíe la copia al otorgante; e i) en la versión inglesa de la recomendación 22, de conformidad con la terminología utilizada en el proyecto de guía para un registro, se indicaría la obligación del otorgante en el apartado a) mediante la palabra “must”, mientras que la obligación del registro se indicaría en el apartado b) con las palabras “specifies” y “makes”.

37. Con sujeción a los cambios mencionados (véanse los párrs. 30 a 36 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó el capítulo III.

F. Inscripción de notificaciones iniciales (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 50 a 71 y A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3, párrs. 1 a 35)

38. Con respecto a la subsección A.2 (Información sobre el otorgante), se convino en lo siguiente: a) se suprimiría la fila “otra entidad” del cuadro que figuraba a continuación del párrafo 66, ya que era demasiado general para servir de orientación y, en todo caso, los Estados promulgantes tendrían que ajustar los ejemplos dados en el cuadro para que se adoptaran a su propio contexto; b) siguiendo el orden de los

ejemplos que figuraban en el cuadro, se invertiría el orden de los párrafos 67 y 68; y c) se reformularían los párrafos 69 a 71 para indicar en qué forma era tratada la dirección del otorgante en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, enumerar cuestiones adicionales que fuera necesario abordar y terminar con una referencia a las recomendaciones del proyecto de guía para un registro que trataran de dichas cuestiones. A ese respecto, también se convino en que en el comentario se explicarían en detalle casos en los que el otorgante tuviese direcciones múltiples o no tuviese ninguna dirección en el Estado en que se encontraba el registro, haciendo una remisión a la recomendación 18, apartado b), que disponía que el acreedor garantizado enviara al otorgante copia de la notificación inicial a la dirección consignada en la notificación y copia de toda notificación de modificación al otorgante a la dirección consignada en la notificación o a la dirección actual que conociera el acreedor garantizado.

39. Con respecto a la subsección A.3 (Información sobre el acreedor garantizado), se acordó lo siguiente: a) se armonizaría el texto de los párrafos 2 y 4; y b) en el párrafo 4 se aclararía que los terceros podrían apoyarse en el hecho de que, incluso en caso de que no se tratara del verdadero acreedor garantizado, la persona mencionada en la notificación como acreedor garantizado podría actuar en nombre del acreedor garantizado y vincularlo, sin tener que determinar cuál era su relación exacta con el verdadero acreedor garantizado.

40. Con respecto a la subsección A.4 (Descripción de los bienes gravados), se convino en que los párrafos 10 y 11 se revisarían para aclarar que la necesidad de modificar la descripción de los bienes gravados en la notificación solo surgiría cuando el producto fuera de algún tipo que no estuviese contemplado en la descripción de los bienes gravados que figura en la notificación inicial.

41. Con respecto a la subsección A.6 (Importe máximo por el que se puede ejecutar la garantía real), se convino en lo siguiente: a) suprimir del párrafo 15 el examen de la posibilidad de que el requisito de especificar en la notificación el importe máximo se utilizara como pretexto para imponer una tasa sobre las operaciones garantizadas, dado que esa cuestión se examinaba en otros sitios (véanse A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3, párr. 19, y A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párr. 56); y b) explicar en el comentario que, de conformidad con la recomendación 11, apartado a), la modificación del importe máximo solo sería válida a partir del momento en que pasara a ser válida la notificación de modificación, de manera que los terceros que se hubieran basado en el importe máximo anterior quedaran protegidos.

42. Con respecto a la subsección A.7 (Efecto de los errores u omisiones sobre la validez de la inscripción registral de una notificación), se convino en lo siguiente: a) incluir en el párrafo 27 una referencia a la parte del proyecto de guía para un registro en que se examinaba la indexación y consulta por números de serie (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 24 a 27); y b) suprimir los párrafos 30 y 31 (con excepción de la primera oración, que se colocaría a continuación del párr. 28), puesto que la cuestión se examinaba en los párrafos 32 a 35.

43. Con respecto a las recomendaciones 23 a 29, se convino en lo siguiente: a) en las recomendaciones 23 y 27, se suprimirían las referencias al representante del acreedor garantizado, dado que en el proyecto de guía para un registro la expresión “acreedor garantizado” incluía al representante, si esa persona se hubiera

identificado en la notificación como el acreedor garantizado; b) se armonizaría la recomendación 24, apartado e), con el comentario correspondiente (véanse A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párr. 56 y el cuadro siguiente); c) se revisaría la recomendación 26, apartado a), para que dijera, por ejemplo, “si el otorgante está sujeto a un procedimiento de insolvencia y el representante de la insolvencia constituye una garantía real sobre los bienes del otorgante ...”, a fin de que no se infiriera que se necesitaba una notificación de modificación en el caso de una garantía real constituida por el otorgante con anterioridad al procedimiento de insolvencia (véanse los párrs. 52 d) y 53 *infra*); d) se suprimiría la recomendación 26, apartados b) y d), y las cuestiones pertinentes se examinarían en el comentario; e) se armonizaría la recomendación 26, apartado c), con el comentario correspondiente (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párr. 66 y el cuadro siguiente) para hacer referencia al fideicomisario o el representante de un patrimonio; f) en el comentario de la recomendación 27, apartado c), se explicaría que el apartado c) tendría escasa importancia a efectos prácticos, dado que sería inhabitual que una persona insolvente o un fideicomisario del patrimonio de una persona fallecida fuera un acreedor garantizado; g) en la recomendación 29, apartados b) a e), se sustituirían las expresiones “inscripción” e “inscripción registral” por la expresión “inscripción de la notificación”, a fin de asegurar la coherencia con otras partes del proyecto de guía para un registro; h) la referencia que se hacía en la recomendación 29 al hecho de que podría quedar privada de validez la inscripción de una notificación no significaba que se denegara la inscripción de información, sino que esta no tendría consecuencias jurídicas; e i) se revisaría la recomendación 29, apartado c), para hacer referencia a un identificador “insuficiente” (en lugar de “incorrecto”) de un otorgante, dado que, conforme a la recomendación 29, apartado a), incluso una notificación en la que figure un identificador incorrecto del otorgante puede surtir efecto (si puede recuperarse mediante una búsqueda en el fichero del registro accesible al público utilizando el identificador correcto del otorgante).

44. Con sujeción a los cambios mencionados (véanse los párrs. 38 a 43 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó el capítulo IV.

G. Inscripción de notificaciones de modificación y cancelación (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 1 a 41)

45. Con respecto a la subsección A.1 (Notificaciones de modificación), se convino en aclarar lo siguiente en el comentario: a) era el acreedor garantizado, no el solicitante de la inscripción, quien tenía derecho a efectuar una modificación; b) no sería obligatorio que en la modificación se hiciera referencia a una subordinación voluntaria; c) el examen era exhaustivo puesto que trataba de todas las modificaciones relativas al contenido mínimo de una notificación, pero no lo era en la medida en que no podía abarcar todos los motivos para efectuar una modificación; d) en el caso de que el otorgante cambiara de nombre, se debería poder recuperar la inscripción buscando por el nombre antiguo o por el nuevo; e) en el *Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual* se adoptaba una posición distinta a la de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* con respecto a la validez de una inscripción registral en caso de transmisión de los bienes gravados (recomendación 244); y f) el sistema de inscripción registral podría estar concebido de manera de admitir la posibilidad de inscribir una notificación de

modificación para dar a conocer una subordinación, pero la adición de nuevas posibilidades supondría un costo.

46. Con respecto a la subsección A.4 (Validez de las notificaciones de modificación o cancelación no autorizadas por el acreedor garantizado), se convino en sustituirla con texto nuevo en el que se describiera la cuestión, se afirmara que dicha cuestión no se examinaba explícita y exhaustivamente en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, se describieran las cuestiones normativas concretas que deberían tratar de resolver los Estados promulgantes y se examinaran algunos posibles enfoques para tratar esas cuestiones. Además, se convino en que en el nuevo texto se expondrían los dos enfoques normativos opuestos (protección de los terceros que consulten el fichero del registro y protección del acreedor garantizado) y se señalaría la necesidad de distinguir entre los casos de fraude cometido por un tercero (que podrían tratar de evitarse mediante mecanismos de acceso seguro) y los casos de error cometido por el acreedor garantizado, sus empleados o agentes (que podrían tratar de evitarse mediante normas de responsabilidad profesional). Por otra parte, se convino en que en el nuevo texto se explicaría que el registro y los terceros de buena fe que lo consultaran no tendrían manera de saber si determinada modificación o cancelación no autorizada se debía a fraude o error. También se convino en aclarar en el nuevo texto que, una vez inscrita una notificación de cancelación, de conformidad con la recomendación 74 de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, el registro tenía la obligación de retirar la notificación en cuestión del fichero del registro accesible al público, independientemente de si estaba autorizada por el acreedor garantizado o no, pues el registro no tenía manera de verificar si una notificación de cancelación había sido autorizada por el acreedor garantizado.

47. Con respecto a la recomendación 30, se convino en mantener los apartados a) y f), para ofrecer orientación en cuanto a las modificaciones relativas a la información que debía consignarse en una notificación, y en suprimir en cambio los apartados b) a e) y examinar esas cuestiones en el comentario (respecto de una modificación de la recomendación 33, apartado g), véase el párr. 57 *infra*).

48. Con sujeción a los cambios mencionados (véanse los párrs. 45 a 47 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó el capítulo V.

H. Criterio y resultados de la consulta (A/CN.9/WG.VI/ WP.54/Add.4, párrs. 42 a 51)

49. Con respecto a la subsección A.2 (Resultados de la consulta), se convino en aclarar lo siguiente en el comentario: a) el número de inscripción era el único criterio de búsqueda aparte del identificador del otorgante; y b) el examen de los resultados aproximados solo se aplicaría a las búsquedas efectuadas utilizando el identificador del otorgante, no el número de inscripción. Con sujeción a esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el capítulo VI.

I. Tasas de inscripción y de consulta (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 52 a 58)

50. Con respecto a la versión inglesa de la recomendación 36, se convino en emplear la palabra “paper” en lugar de las palabras “paper-based”. Con sujeción a esos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el capítulo VII.

J. Anexo I. Terminología y recomendaciones (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.5)

51. Tras haber aprobado el comentario y las recomendaciones de todos los capítulos del proyecto de guía para un registro, el Grupo de Trabajo señaló que había aprobado también el Anexo I, en el que se reproduce la terminología y las recomendaciones, recogidas en los capítulos pertinentes del proyecto de guía.

K. Anexo II. Ejemplos de formularios de registro (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.6)

52. El Grupo de Trabajo pasó luego a examinar los ejemplos de formularios del registro, que figuran en el anexo II del proyecto de guía para un registro. Con respecto al formulario A (Ejemplo de notificación inicial), se acordó lo siguiente: a) en el descargo de responsabilidad incluido en la parte superior del formulario A se mencionaría también que era responsabilidad del solicitante de la inscripción velar por que toda la información incluida en la notificación fuera completa, exacta y jurídicamente vinculante (se señaló que el mismo cambio se debería introducir también en los formularios B, C, D y E); b) en la indicación del momento en que adquiere validez la inscripción, indicación que generaría automáticamente el registro, se agregarían los minutos y segundos (se señaló que el mismo cambio se debería introducir también en los formularios B, C, D, E, G y H); c) en el texto inglés, la referencia a “additional grantor information” se revisaría, en todo el texto del formulario A, siguiendo un texto que dijera, por ejemplo, “additional information about the grantor” y, en todos los idiomas, se pondría entre corchetes y acompañada de una nota que se ajustara al texto de la parte pertinente del comentario (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párr. 53; se señaló que el mismo cambio se debería introducir en el formulario B); d) se revisaría la sección A.3 para indicar si el otorgante era la persona que estaba sujeta al procedimiento de insolvencia o el representante de esa persona en la insolvencia; e) en todo el formulario A se suprimiría la referencia a “un consorcio o una empresa conjunta” y a “una entidad diferente de las arriba mencionadas”, y se revisaría la referencia a “una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre se ha dado” introduciendo un texto que dijera, por ejemplo, “un fideicomisario o representante de un patrimonio” (se señaló que el mismo cambio se debería introducir también en el formulario B); f) en la sección C se suprimiría la referencia a una descripción de los bienes gravados mediante un número de serie; g) en la sección D se haría referencia a la duración de la inscripción, y en el comentario se explicaría que esa referencia significaba el último día de dicho período; y h) en la sección G se mantendría la referencia a la indicación de que la inscripción era transitoria, y se suprimiría en

cambio la referencia al criterio de indexación y la fecha y hora en que la inscripción adquiriría validez por no ser ya necesaria.

53. Como resultado del cambio introducido en la sección A.3 del formulario A (véase el párr. 52 d) *supra*), el Grupo de Trabajo volvió a examinar la recomendación 26, apartado a) (véase el párr. 43 c) *supra*). Predominó la opinión de que la respuesta a la pregunta de quién podría ser la persona que tendría el derecho a otorgar una garantía real sobre los bienes que eran parte del patrimonio de la insolvencia (o sea, la persona que estaba sujeta a un procedimiento de insolvencia o el representante de esa persona en la insolvencia) y, por tanto, la respuesta a la pregunta de la persona cuyo nombre debería consignarse como otorgante en la sección A.1 o A.2 del formulario A, dependería de la ley del Estado promulgante, que podría diferir de un Estado a otro. Por consiguiente, se convino en que se revisaría la recomendación 26 a) (y el comentario pertinente) a fin de indicar que el identificador del otorgante podría ser o bien el nombre de la persona que estaba sujeta al procedimiento de insolvencia o el representante de esa persona en la insolvencia.

54. Con respecto al formulario B (ejemplo de notificación de modificación), se acordó lo siguiente: a) la lista de acciones enunciadas en la parte superior del formulario se suprimiría y se darían instrucciones a los autores de una inscripción que rellenaran en el formulario tantos espacios como necesitaran; b) con respecto a la modificación global de aplicar las opciones ofrecidas en la recomendación 31, en el comentario se explicaría que los Estados promulgantes necesitarían elaborar un formulario para que un acreedor garantizado aplicara esa modificación o una solicitud para que el acreedor garantizado solicitara al registro que introdujera dicha modificación; c) en la sección D, se insertaría un texto que dijera, por ejemplo, “consigne el nombre del otorgante al que se refiere la modificación”; y d) en la sección G se insertaría un texto como, por ejemplo, “consigne el nombre del acreedor garantizado al que se refiere la modificación”.

55. Con respecto al formulario C (ejemplo de notificación obligatoria de modificación), se acordó lo siguiente: a) se revisaría el encabezamiento con un texto del siguiente tenor “ejemplo de notificación de modificación con arreglo a una orden judicial o administrativa” (se señaló que en el encabezamiento del formulario E se debería introducir un cambio similar); b) en la sección B se haría referencia también a “los cambios” de información con arreglo a una orden judicial o administrativa; c) en la sección C se haría referencia a un “solicitante de la inscripción”, y a su nombre y cargo, así como al nombre de la autoridad y su dirección (se señaló que el mismo cambio se debería introducir también en el formulario E); d) en el comentario a la recomendación 33 se debería explicar que un Estado promulgante necesitaría determinar si se debería adjuntar una copia de la orden completa (que indique los hechos, la fundamentación y la decisión propiamente tal) o solo la decisión propiamente tal y si se debería adjuntar una copia certificada y, en tal caso, que constituiría una copia certificada con arreglo a la ley del Estado promulgante (se señaló que el mismo comentario se aplicaría también con respecto al formulario E); y e) en la sección D se haría referencia a una copia de la orden judicial o administrativa (el mismo cambio se debería introducir también en el formulario E).

56. Con respecto al formulario D (Ejemplo de notificación de cancelación), se acordó lo siguiente: a) revisarlo para hacer referencia al “Número de inscripción de

la notificación inicial que se va a cancelar”; b) añadir una nota para avisar al acreedor garantizado de las consecuencias jurídicas de la cancelación; y c) incluir en el comentario un examen de la cuestión de las cancelaciones hechas de forma no intencionada por los acreedores garantizados y las formas de prevenirlas (por ejemplo, exigiendo que se consigne información adicional, como el identificador del otorgante, en la notificación de cancelación, y disponiendo que se rechace la notificación de cancelación si el número de inscripción no coincide con el identificador del otorgante, o concibiendo el registro de forma que cuando se teclee el número de inscripción aparezca en la pantalla todo el fichero relativo a la notificación que se vaya a cancelar).

57. En el contexto del examen del formulario E, se acordó que en la recomendación 33, apartado g), se armonizaría la variante A con la variante B para exigir que se adjunte una copia de la correspondiente orden judicial o administrativa, en lugar del documento original (véase párr. 47 *supra*).

58. Con respecto al formulario F (Ejemplo de solicitud de consulta), se acordó lo siguiente: a) insertar al principio del formulario un texto similar al siguiente: “Las secciones A y B son alternativas y solo es necesario rellenar una de ellas; b) suprimir la referencia a la hora, dado que esa información se consignaría en el formulario G sobre el resultado de una consulta; y c) suprimir la referencia a la “información adicional sobre el otorgante”, dado que, conforme a la recomendación 34, esa información no constituía un criterio de consulta.

59. Con respecto al formulario G (Ejemplo de resultado de una consulta), se acordó lo siguiente: a) de conformidad con la terminología utilizada en el proyecto de guía para un registro, se haría referencia a la “recuperación” de notificaciones; b) para indicar qué notificación coincidía con el criterio de consulta conforme a la recomendación 35, apartado a), se haría referencia al criterio de consulta utilizado; y c) se examinaría en el comentario el tipo de información que se facilitaría en el resultado de una consulta a quienes hubieran hecho la consulta (toda la información de un documento adjunto o un cuadro, o alguna información relativa a las notificaciones que coincidieran con el criterio de consulta). A ese respecto, el Grupo de Trabajo examinó la cuestión de las “fechas de validez” y señaló que en el comentario correspondiente (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párr. 51) se hacía un examen lo suficientemente exhaustivo de esa cuestión.

60. Con respecto al formulario H (Ejemplo de rechazo de una solicitud de inscripción o de consulta), se acordó lo siguiente: a) el formulario emplearía casillas marcables para indicar al solicitante de la inscripción o la consulta el motivo o los motivos por los que se rechazaba la solicitud de inscripción o de consulta; b) se indicaría en el formulario la hora a la que se hubiera rechazado la solicitud; c) de conformidad con la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo en el periodo de sesiones en curso (véase párr. 43 *supra*), se suprimiría la referencia que se hacía al representante del acreedor garantizado en la sección A.1.b); d) se combinarían los apartados b) y c) de la sección A.2 y se revisaría la sección para que dijera, por ejemplo, “No se ha consignado información alguna en forma legible”; e) se revisaría la sección B para que dijera, por ejemplo, “La solicitud de consulta se ha rechazado porque no se ha consignado en forma legible un criterio de consulta en el espacio previsto”; f) se explicaría en el comentario que el formulario H se utilizaría por lo general en un registro que utilizara documentos en papel, pues un registro electrónico que funcionara de forma correcta rechazaría automáticamente una

solicitud de inscripción o de consulta que no incluyera toda la información requerida.

61. Con sujeción a los cambios mencionados (véanse los párrs. 52 a 60 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó los ejemplos de formularios de registro y revisó las recomendaciones 26, apartado a), y 33, apartado g), variante A.

L. Título del proyecto de guía para un registro

62. El Grupo de Trabajo decidió que el título del proyecto de guía para un registro sería “Guía de la CNUDMI relativa a la Aplicación de un Registro de las Garantías Reales”. Se convino en que era un título apropiado, sobre todo porque hacía referencia al contenido del proyecto de guía para un registro, así como también por su relación con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

V. Proyecto de ley modelo sobre las operaciones garantizadas

63. Una vez concluidas sus deliberaciones sobre el proyecto de guía para un registro, el Grupo de Trabajo intercambió puntos de vista sobre el proyecto de ley modelo sobre las operaciones garantizadas (“proyecto de ley modelo”), en particular con respecto a su ámbito de aplicación. En primer lugar, el Grupo de Trabajo expresó su reconocimiento a la Comisión por su decisión de confiarle la preparación de una ley modelo sobre las operaciones garantizadas sencilla, breve y concisa, que se basara en las recomendaciones generales de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y se ajustara a todos los textos preparados por la CNUDMI en materia de operaciones garantizadas⁶, y a la Secretaría, por preparar un proyecto preliminar de proyecto de ley modelo. Se expresó la opinión de que en el mandato de la Comisión relativo al proyecto de ley modelo no estaba implícito que quedaran excluidas del ámbito del proyecto de ley modelo las cuestiones que en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* eran objeto de recomendaciones sobre determinados bienes. Se indicó que el mandato de la Comisión sí requería que las decisiones relativas al ámbito se adoptaran sobre la base del valor económico de la aplicación del proyecto de ley modelo a una transacción, y no de que el bien fuera objeto de una recomendación relativa a determinados bienes.

64. Según otra opinión, los principales elementos del mandato confiado por la Comisión al Grupo de Trabajo consistían en que el texto que se preparara fuera sencillo, conciso y en que complementara la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Se señaló que, antes de examinar las disposiciones del proyecto de ley modelo, era prematuro estudiar en detalle, o remitir a la Comisión, la cuestión del ámbito del proyecto de ley modelo. A ese respecto, se observó que el proyecto de ley modelo podía cumplir las tres condiciones establecidas por la Comisión si su ámbito era amplio e incluía principios generales, pero no así si tenía un ámbito amplio pero incluía disposiciones detalladas. También se señaló que, si bien la sencillez podía ser un criterio subjetivo, la concisión era un criterio objetivo y suponía, por ejemplo, un número limitado de disposiciones. También se observó

⁶ *Ibid.*

que, de todos modos, el proyecto de ley modelo debía completar la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y no reemplazarla.

VI. Labor futura

65. El Grupo de Trabajo remitió el proyecto de guía para un registro a la Comisión para su aprobación en su próximo 46º período de sesiones.

66. El Grupo de Trabajo señaló que, de acuerdo con el calendario provisional de reuniones, su 24º período de sesiones tendría lugar en Viena del 7 al 11 de octubre de 2013, a reserva de que la Comisión confirmara esas fechas en su 46º período de sesiones.

D. Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23º período de sesiones

(A/CN.9/WG.VI/WP.54 y Add.1 a Add.6)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
Prefacio	
Introducción	1-53
A. Propósito del proyecto de guía sobre el registro y su relación con la <i>Guía sobre las Operaciones Garantizadas</i>	1-7
B. Terminología e interpretación.	8-16
C. Objetivos clave y principios fundamentales de un registro eficiente	17
D. Información general sobre el régimen de las operaciones garantizadas y la función de la inscripción registral	18-53
1. Observaciones generales	18
2. Concepto de la garantía real	19-21
3. Constitución de una garantía real	22-26
4. Oponibilidad a terceros de una garantía real.	27-32
5. Prelación de una garantía real.	33-53

Prefacio

En su 42º período de sesiones (Viena, 29 de junio a 17 de julio de 2009), la Comisión tomó nota con interés de los temas de trabajo futuros examinados por el Grupo de Trabajo VI en sus períodos de sesiones 14º y 15º (A/CN.9/667, párr. 141, y A/CN.9/670, párrs. 123 a 126). En ese período de sesiones, la Comisión acordó que la Secretaría organizara un coloquio internacional a principios de 2010 para recabar las opiniones y el asesoramiento de expertos acerca de la posible labor futura en materia de garantías reales¹. De conformidad con esa decisión², la Secretaría organizó un coloquio internacional sobre las operaciones garantizadas (Viena, 1 a 3 de marzo de 2010). En el coloquio se examinaron varios temas, incluida la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles, las garantías reales sobre valores bursátiles que no estén en poder de intermediarios, una ley modelo sobre las operaciones garantizadas, una guía contractual para las operaciones garantizadas, la concesión de licencias de propiedad intelectual y la puesta en práctica de los textos de la CNUDMI sobre garantías reales. Participaron

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párrs. 313 a 320.*

² *Ibid.*

en el coloquio expertos procedentes de los países, de organizaciones internacionales y del sector privado³.

En su 43º período de sesiones (Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010), la Comisión examinó una nota de la Secretaría sobre la posible labor futura en materia de garantías reales (A/CN.9/702 y Add.1). En la nota se abordaban todos los temas examinados en el coloquio. La Comisión reconoció que todos los temas presentaban interés y debían mantenerse en su futuro programa de trabajo para su examen en un futuro período de sesiones sobre la base de las notas que pudiera preparar la Secretaría, dentro de los límites de los recursos disponibles. No obstante, habida cuenta de los limitados recursos de que disponía, la Comisión acordó que debía concederse prioridad a la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles⁴.

Prevaleció el parecer, a dicho respecto, de que un texto relativo a la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles sería un complemento valioso de la labor ya realizada por la Comisión en materia de operaciones garantizadas y ofrecería a los Estados la orientación que tan urgentemente requerían para el establecimiento y el funcionamiento de los registros de garantías reales. Se afirmó que la reforma del régimen de las operaciones garantizadas no podía llevarse a cabo eficazmente sin haber establecido previamente un registro de las garantías reales que fuera eficiente y públicamente accesible. También se puso de relieve que en la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* (“*Guía sobre las Operaciones Garantizadas*”) no se abordaban con suficiente detalle las diversas cuestiones jurídicas, administrativas, de infraestructura y funcionales que era preciso resolver para asegurar el buen funcionamiento de un registro⁵.

La Comisión convino también en que, si bien podía confiarse al Grupo de Trabajo la decisión sobre la forma y la estructura específicas del texto, ese texto podría: a) incluir principios, directrices, un comentario, recomendaciones o un reglamento modelo; y b) basarse en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, en los textos preparados por otras organizaciones y en los regímenes nacionales que habían establecido registros de las garantías reales similares al registro recomendado por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Tras deliberar, la Comisión decidió encomendar al Grupo de Trabajo la preparación de un texto relativo a la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles⁶.

En su 18º período de sesiones (Viena, 5 a 10 de noviembre de 2010), el Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles” (A/CN.9/WG.VI/WP.44 y Add.1 y 2). El Grupo de Trabajo expresó en primer lugar su amplio apoyo a la preparación de un texto relativo a la inscripción registral de las garantías reales sobre bienes muebles, observando que la práctica financiera había demostrado claramente que la eficacia de un régimen de las operaciones garantizadas dependía de que se dispusiera de un

³ Véanse los documentos del coloquio en www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/3rdint.html.

⁴ *Ibid.*, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17 y Corr.1), párrs. 264 y 273.

⁵ *Ibid.*, párr. 265.

⁶ *Ibid.*, párrs. 266 y 267.

sistema de inscripción registral eficiente (véase A/CN.9/714, párr. 12). En cuanto a la forma y la estructura del texto que había de prepararse, el Grupo de Trabajo partió del supuesto de que se prepararía una guía para la creación y el funcionamiento de un registro de las garantías reales sobre bienes muebles en la que se incluirían principios, directrices, comentarios y tal vez un reglamento modelo. El Grupo de Trabajo convino también en que el texto que se propusiera para dicha guía fuera compatible con el régimen legal de las operaciones garantizadas recomendado por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, sin dejar, por ello, de tener en cuenta la diversidad de los enfoques adoptados en los reglamentos por los que se regían los registros más modernos tanto nacionales como internacionales. Se observó además que, con arreglo a lo recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (recomendación 54, apartado j)), la guía que se propusiera para los futuros registros debería tener en cuenta la necesidad de facilitar la inscripción de notificaciones consignadas sobre soportes tanto electrónicos como de papel, a fin de que las partes interesadas pudieran inscribir su notificación o hacer su consulta por vía electrónica o sobre papel (A/CN.9/714, párr. 13). Se pidió a la Secretaría que preparara un proyecto de texto para la guía registral propuesta a la luz de las deliberaciones y de las conclusiones a que llegara el Grupo de Trabajo (A/CN.9/714, párr. 11).

En su 19º período de sesiones (Nueva York, 11 a 15 de abril de 2011), el Grupo de Trabajo examinó las notas preparadas por la Secretaría, tituladas “Proyecto de guía para un registro de las garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.46 y Add.1 y 2) y “Proyecto de reglamento modelo” (A/CN.9/WG.VI/WP.46/Add.3). El Grupo de Trabajo examinó en primer lugar la forma y el contenido del texto que habría de prepararse. Se expresó la opinión de que habría que elaborar una guía autónoma en la que figurara una parte pedagógica que presentara el régimen de las operaciones garantizadas que se recomendaba en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, así como una parte práctica, que consistiera en un reglamento modelo para la inscripción de garantías y un comentario al respecto (véase A/CN.9/719, párr. 13). Otra opinión fue que debía hacerse hincapié en un reglamento modelo para la inscripción de garantías y el comentario al respecto, que sirviera de guía práctica para los Estados que hubieran promulgado el régimen de las operaciones garantizadas recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* con respecto a las cuestiones que habría que abordar a la hora de establecer y administrar un registro general de las garantías reales (véase A/CN.9/719, párr. 14). En ese período de sesiones se manifestaron también diversas opiniones acerca de si el texto debía presentarse como reglamento modelo o como recomendaciones (A/CN.9/719, párr. 46). El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada del texto que reflejara las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/714, párr. 12).

En su 44º período de sesiones (Viena, 27 de junio a 8 de julio de 2011), la Comisión examinó los informes de los períodos de sesiones 18º y 19º del Grupo de Trabajo (A/CN.9/714 y A/CN.9/719, respectivamente). En ese período de sesiones, se destacó la importancia de la labor efectuada por el Grupo de Trabajo VI, en particular teniendo en cuenta los esfuerzos que estaban realizando varios Estados para establecer un registro general de las garantías reales y las importantes consecuencias beneficiosas que tendría el funcionamiento de un registro de ese tipo en la oferta y el costo del crédito. En cuanto a la forma y el contenido del texto que habría de prepararse, se indicó que, optando por el enfoque seguido en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, el texto debía presentarse en forma de guía con un

comentario y recomendaciones, y no como un texto con un reglamento modelo y su correspondiente comentario. A este respecto, se observó que la siguiente versión del texto sometido al Grupo de Trabajo se presentaría de forma tal que se dejara abierta la cuestión hasta que el Grupo de Trabajo formulara una decisión. Tras un debate, la Comisión convino en que no era preciso modificar el mandato del Grupo de Trabajo, que confiaba a este la decisión sobre la forma y el contenido del texto que había de prepararse, y que, en todo caso, la Comisión adoptaría la decisión final una vez que el Grupo de Trabajo hubiera concluido su labor y le hubiera presentado el texto⁷.

En su 20º período de sesiones (Viena, 12 a 16 de diciembre de 2011), el Grupo de Trabajo prosiguió su labor basándose en una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía para un registro de las garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.48 y Add.1 a 3). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo convino en que el texto debía adoptar la forma de una guía (“proyecto de guía sobre el registro”) con un comentario y recomendaciones similares a los de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Además, el Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en que, cuando en el proyecto de guía sobre el registro se propusieran variantes, se incluyeran ejemplos de reglas modelo en un anexo de dicho proyecto (A/CN.9/740, párr. 18). En cuanto a la presentación del texto, se acordó que el proyecto de guía sobre el registro se presentara como texto aparte, independiente y amplio, que estuviera en consonancia con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y que se titulara provisionalmente “Guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de las garantías reales” (A/CN.9/740, párr. 30).

En su 21º período de sesiones (Nueva York, 14 a 18 de mayo de 2012), el Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía legislativa técnica relativa a la aplicación de la Guía para un registro de las garantías reales: Anexo I. Terminología y recomendaciones” (A/CN.9/WG.VI/WP.50 y Add.1 y 2). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección relativa a la terminología y de las recomendaciones del proyecto de guía sobre el registro (A/CN.9/743, párr. 21). Además, el Grupo de Trabajo acordó que el proyecto de guía se concluyera y se sometiera a la aprobación de la Comisión en su 46º período de sesiones, previsto para 2013 (A/CN.9/743, párr. 73).

En su 45º período de sesiones (Nueva York, 25 de junio a 6 de julio de 2012), la Comisión examinó los informes de los períodos de sesiones 20º y 21º del Grupo de Trabajo (A/CN.9/740 y A/CN.9/743, respectivamente). En ese período de sesiones, la Comisión expresó su gratitud al Grupo de Trabajo y le pidió que agilizara y concluyera su labor, de modo que el proyecto de guía sobre el registro se le pudiera presentar para darle su aprobación final y adoptarlo en su 46º período de sesiones, que se celebraría en 2013⁸.

En su 22º período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales” (A/CN.9/WG.VI/WP.52 y Add.1 a 6). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido del proyecto de guía sobre el registro y solicitó a la Secretaría que preparase una versión revisada del texto que reflejara las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/764, párr. 15).

⁷ *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 233.

⁸ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 99.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que el prefacio será actualizado después de cada sesión del Grupo de Trabajo y quedará terminado después que la Comisión apruebe el proyecto de guía sobre el registro, en su 46º período de sesiones, en 2013.]

Introducción

A. Propósito del proyecto de guía sobre el registro y su relación con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*

1. La *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* (“*Guía sobre las Operaciones Garantizadas*”) trata de toda la gama de cuestiones que deberían abordarse en un régimen moderno de operaciones garantizadas (complementada, en lo que respecta a las garantías reales sobre la propiedad intelectual, por el *Suplemento relativo a las garantías reales sobre propiedad intelectual*; el “*Suplemento*”). La creación de un registro que permita al público informarse acerca de la posible existencia de una garantía real sobre bienes muebles constituye una característica fundamental del régimen que se recomienda en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y de las iniciativas favorables a una reforma general de la legislación en esta esfera. En el capítulo IV de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se hacen ya comentarios y recomendaciones sobre muchas cuestiones concernientes a un registro general de las garantías reales. Además, en los capítulos III y V de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se tratan las cuestiones conexas de la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real.

2. Sin embargo, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no se examinan, al menos en detalle, la multitud de cuestiones jurídicas, tecnológicas, administrativas y funcionales que habrán de resolverse para la creación y el buen funcionamiento de un registro general de las garantías reales. Ello está de acuerdo con el enfoque legislativo más común, según el cual las normas detalladas aplicables al establecimiento y funcionamiento del registro, así como al proceso de inscripción y búsqueda o consulta, se tratan en reglamentos, directrices ministeriales y demás. De este modo, el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de las garantías reales (“proyecto de guía sobre el registro”) tiene por objeto poner en práctica la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* abordando estas cuestiones en mayor detalle.

3. Conviene subrayar desde un principio que las recomendaciones del proyecto de guía sobre el registro se formulan para ser aplicadas por los Estados que han establecido o van a establecer un régimen de operaciones garantizadas que responda, básicamente, a las recomendaciones formuladas en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Por ejemplo, para poder aplicar las recomendaciones del proyecto de guía sobre el registro, un Estado tendría que haber promulgado o estar dispuesto a promulgar una ley sobre operaciones garantizadas que previera la inscripción de notificaciones (más que de documentos) y tratara la inscripción registral como método para hacer que una garantía real fuera oponible a terceros (y no tanto para crear una garantía real). De ello se desprende que, a fin de comprender el marco jurídico en que se propone que funcione el registro, todo usuario del proyecto de guía sobre el registro debería tener un conocimiento básico del régimen

de operaciones garantizadas que se prevé en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Así, en la sección E de la Introducción al proyecto de guía sobre el registro se ofrece una descripción concisa del régimen de operaciones garantizadas recomendado por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y en otros capítulos del proyecto de guía sobre el registro se incluye orientación adicional. Con todo, si se quiere alcanzar una comprensión cabal del tema, convendría leer el proyecto de guía sobre el registro junto con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

4. La experiencia de los Estados que han establecido ya el tipo de registro general de las garantías reales previsto en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* es una clara muestra de las grandes ventajas que la tecnología de la información aporta a la eficiencia de un registro de este tipo. En particular, en lo relativo a los aspectos técnicos de diseño y funcionamiento del registro, el proyecto de guía sobre el registro trata de sacar enseñanzas de esos precedentes nacionales. Además, en el proyecto de guía se recurre a otras fuentes internacionales relacionadas con las operaciones garantizadas, entre las que cabe citar las siguientes:

a) Reforma legislativa y de política registral del Banco Asiático de Desarrollo: guía de registros de bienes muebles (2002);

b) Publicidad de las garantías reales: principios rectores para la elaboración de un registro de gravámenes, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) (2004);

c) Publicidad de las garantías reales: Definición de normas del BERD para los registros de gravámenes (2005);

d) Reglamento Modelo para el Registro en virtud de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias (2009) de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

e) Principios, definiciones y reglamento modelo de un proyecto de marco común de un derecho privado europeo, volumen 6, libro IX (Garantías reales sobre bienes muebles), capítulo 3 (Oponibilidad a terceros), sección 3 (Inscripción), 2010, preparado por el Grupo de estudio sobre un código civil europeo y por el Grupo de investigaciones acerca del derecho privado de la CE (Acquis Group), 2010;

f) Publicación de la Corporación Financiera Internacional (Grupo del Banco Mundial) sobre los sistemas de operaciones garantizadas y los registros de gravámenes (2010); y

g) Convenio relativo a las garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil (Ciudad del Cabo, 2001) y Normas y procedimientos para el registro internacional, documento 9864, Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (cuarta edición, 2010).

5. Las fuentes nacionales, regionales e internacionales que se acaban de citar están de acuerdo en general, pero no siempre hasta el último detalle, con las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Siempre que ha sido procedente, en el proyecto de guía sobre el registro se explica la razón de ser del enfoque que se recomienda en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* en comparación con otros enfoques posibles.

6. El proyecto de guía sobre el registro está dirigido a todas las personas interesadas en dicho registro o que hayan de participar activamente en su diseño y

puesta en marcha, o que puedan verse afectadas por su apertura o estar interesadas en su creación y funcionamiento, entre las que cabe citar:

- a) Los encargados de formular políticas para la aplicación de las recomendaciones contenidas en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, especialmente en relación con la creación de un registro de garantías reales;
- b) Los diseñadores de sistemas de registro, incluido el personal técnico encargado de preparar las especificaciones de diseño o de cumplir los requisitos del equipo y los programas informáticos del registro;
- c) Los administradores y el personal del registro;
- d) Los usuarios del registro, incluidos los posibles acreedores garantizados, las agencias de información sobre solvencia crediticia, otros acreedores del otorgante de una garantía real y el representante de la insolvencia del otorgante, así como todas las demás personas cuyos derechos podrían verse afectados por una garantía real, por ejemplo, el posible comprador de un bien gravado;
- e) La comunidad jurídica en general (jueces, árbitros y abogados en ejercicio); y
- f) Toda persona o entidad que haya de intervenir en la reforma del régimen de las operaciones garantizadas y en la prestación de asistencia técnica (tales como el Grupo del Banco Mundial, el BERD, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo).

7. En el proyecto de guía sobre el registro se utiliza una terminología jurídica genérica y neutral, compatible con la empleada en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Por consiguiente, puede adaptarse fácilmente a las diversas tradiciones jurídicas y los estilos de redacción propios de los distintos Estados. El proyecto de guía sobre el registro se ha formulado también con flexibilidad a fin de permitir su aplicación de conformidad con las convenciones de redacción locales en cuanto a los tipos de normas que han de incorporarse en las leyes principales y cuáles habrán de relegarse a los reglamentos o a directrices ministeriales o administrativas.

B. Terminología e interpretación

8. La sección sobre terminología e interpretación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la Introducción, secc. B, párr. 20) se aplica también al proyecto de guía sobre el registro, salvo en la medida en que se modifica más abajo. La terminología del proyecto de guía sobre el registro refleja igualmente el refinamiento de estas definiciones y las explicaciones de términos adicionales que se encuentran en los diversos capítulos de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Por ejemplo, cuando en el proyecto de guía sobre el registro se usa la expresión “bien futuro”, se está haciendo referencia a cualquier bien que empiece a existir o sea adquirido por el otorgante después del momento en que se concierta el acuerdo de garantía (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párr. 8; cap. II, párr. 51; y cap. V, párr. 151).

9. Sin embargo, en el proyecto de guía sobre el registro se modifican ciertas disposiciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* relativas a la

terminología y la interpretación a los efectos de su utilización en el proyecto de guía y también se introducen otros términos, según se indica a continuación:

a) Dirección

Por “dirección” se entenderá: i) una dirección física, con nombre y número de calle, ciudad, código postal y Estado; ii) un número de apartado postal, ciudad, código postal y Estado; iii) una dirección electrónica; o iv) una dirección que sirva para comunicar información.

b) Modificación

Por “modificación” se entenderá el cambio de la información contenida en una notificación inscrita previamente en el registro a la que se refiera la modificación.

10. La inscripción de una notificación de modificación no significa que se supriman del fichero del registro las notificaciones inscritas con anterioridad relacionadas con la notificación de modificación. No obstante, puede tener el efecto de modificar o dejar sin validez una notificación inscrita anteriormente con respecto a una garantía real determinada (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párr. 46, y A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 1 a 22).

c) Cancelación

Por “cancelación” se entenderá la retirada del fichero del registro accesible al público de [toda] la información consignada en una notificación inscrita previamente en el registro a la que se refiera la cancelación.

11. La consecuencia jurídica de inscribir una notificación de cancelación en el registro es que deja de ser válida la notificación inscrita anteriormente a la que hace referencia (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 23 a 25).

d) Espacio previsto

Por “espacio previsto” se entenderá el espacio en el formulario de notificación prescrito designado para consignar el tipo de información especificado.

e) Otorgante

Por “otorgante” se entenderá la persona identificada en la notificación como otorgante.

f) Ley

Por “ley” se entenderá la ley del Estado promulgante que rijan las garantías reales sobre bienes muebles.

12. El régimen de las operaciones garantizadas del Estado promulgante tiene que concordar sustancialmente con las recomendaciones de la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas* (véase el párr. 3 *supra*).

g) Notificación

Por “notificación” se entenderá toda comunicación escrita (consignada en papel o electrónica) enviada al registro de información en relación con una garantía real; la notificación podrá ser de una notificación inicial, una notificación de modificación o una notificación de cancelación.

13. En el contexto de la inscripción registral, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* emplea el término “notificación” para referirse tanto al formulario que el solicitante de la inscripción utiliza para presentar información al registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, secc. B, “notificación”, y recomendaciones 54, apartado b), y 57), como a “la información contenida en una notificación” o “el contenido de la notificación” (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 54, apartado d), y 57). En el proyecto de guía sobre el registro se emplea el término “notificación” de la misma manera.

h) Solicitante de la inscripción

Por “solicitante de la inscripción” se entenderá la persona que rellena un formulario de notificación y lo presenta al registro [y que puede ser un proveedor de servicios].

14. El solicitante de la inscripción puede ser el acreedor garantizado (incluido un agente o fideicomisario en el caso de un consorcio de prestamistas) o su representante (por ejemplo, un bufete de abogados u otro proveedor de servicios identificado en la notificación como acreedor garantizado). El proveedor de servicios de mensajería u otros servicios postales utilizado por el solicitante de la inscripción para transmitir la notificación no es el autor, y no es necesario conocer su identidad.

i) Director del registro

Por “director del registro” se entenderá la persona nombrada con arreglo a la ley y el reglamento para que supervise y administre el funcionamiento del registro.

j) Inscripción

Por “inscripción” se entenderá la incorporación en el registro [el fichero] [la base de datos] de la información consignada en una notificación.

k) Número de inscripción

Por “número de inscripción” se entenderá el número único asignado por el registro a una notificación inicial y permanentemente asociado a esa notificación y toda notificación conexas.

l) Fichero del registro

Por “fichero del registro” se entenderá la información contenida en todas las notificaciones inscritas que se almacena [el fichero] [la base de datos] y que consta del fichero a disposición del público (fichero del registro accesible al público) y el fichero que se ha suprimido del fichero del registro accesible al público (archivos del registro).

15. Dado que la expresión “fichero del registro” se refiere a la información contenida en todas las notificaciones inscritas (y no solamente en las relacionadas con un determinado otorgante), para remitirse a una notificación concreta contenida en el fichero del registro se hace referencia a una “notificación inscrita” en lugar de al “fichero del registro”.

m) Reglamento

Por “reglamento” se entenderá el conjunto de reglas que aplique el Estado promulgante respecto del registro, tanto si dichas reglas figuran en directrices administrativas o en la ley sustantiva sobre las operaciones garantizadas.

16. La forma y el contenido exactos del reglamento dependerán de la política legislativa y las técnicas de redacción de cada Estado promulgante. Por ejemplo, si el régimen sobre las operaciones garantizadas consiste en dos o más leyes (como una relativa a las cuestiones de fondo, otra a los conflictos de leyes y otra a la creación del registro), algunas reglas relacionadas con la inscripción registral podrán promulgarse como legislación subordinada a todas esas leyes (por ejemplo, un reglamento aprobado por separado).

n) Acreedor garantizado

Por “acreedor garantizado” se entenderá la persona indicada en la notificación como el acreedor garantizado [y podrá ser el acreedor garantizado o su representante].

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que: a) los términos “modificación” y “cancelación” se explican mediante una referencia a su significado genérico, en lugar de a su efecto legal, que se examina en el comentario; b) el texto que figura entre corchetes en relación con el término “cancelación” podría ser necesario para distinguir entre una cancelación y una modificación; c) el término “notificación” se explica mediante una referencia tanto al medio como a la información contenida en él; d) la expresión “solicitante de la inscripción” se explica mediante una referencia a su significado tal como suele entenderse (el texto que figura entre corchetes podría mantenerse en la terminología o en el comentario); e) la expresión “fichero del registro” se emplea para reflejar el contenido (información) haciendo referencia al continente (la base de datos); f) la expresión “acreedor garantizado” es una expresión nueva que se introduce para aclarar que el registro puede confiar en la persona que se identifica en la notificación como acreedor garantizado o acreedor garantizado inscrito en el registro (el texto que figura entre corchetes podría mantenerse en la terminología o en el comentario). Dado que el lector medio del proyecto de guía sobre el registro puede no tener clara la diferencia entre la expresión “fichero del registro” (el contenido) y la expresión “base de datos” (el continente), el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si: a) habría que explicar la diferencia entre las dos expresiones en el comentario; o b) dado que en las recomendaciones de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas solo se emplea la expresión “fichero del registro”, y que en la mayoría de las recomendaciones del proyecto de guía sobre el registro se emplea la expresión “fichero del registro” (véanse, por ejemplo, las recomendaciones 3, apartado e), y 16), debería reemplazarse la referencia a la expresión “base de datos” en la terminología (apartados j) y l)) y en las recomendaciones 3, apartados d) y g), y 11 con una referencia a la expresión “fichero del registro” (en el sentido tanto del contenido como del continente). El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar también si además habría que explicar el término “registro” con un texto como el siguiente: Por “registro” se entenderá un sistema establecido para inscribir información relativa a las garantías reales sobre bienes muebles”].

C. Objetivos clave y principios fundamentales de un registro eficiente

17. El registro de garantías reales previsto en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y el proyecto de guía sobre el registro se basa en los siguientes principios generales:

a) Las directrices jurídicas y de funcionamiento que han de regir los servicios del registro, incluidas la inscripción y las consultas, deberían ser sencillas, claras y precisas para todos los posibles usuarios; y

b) Los servicios del registro, incluidos los de inscripción y consulta, deberían estar diseñados con miras a que sean tan rápidos y económicos como sea posible, velando al mismo tiempo por la seguridad y accesibilidad de la información incorporada en el fichero del registro.

D. Información general sobre el régimen de las operaciones garantizadas y la función de la inscripción registral

1. Observaciones generales

18. Como ya se ha mencionado, el registro general de las garantías reales es parte integrante del régimen de las operaciones garantizadas recomendado por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Los posibles usuarios del proyecto de guía sobre el registro no necesariamente serán expertos en los detalles de ese régimen ni tendrán siquiera formación jurídica. Por lo tanto, en esta sección se ofrece información general, prestando especial atención a la función jurídica y a las consecuencias de la inscripción registral. Se recomienda al lector que, para obtener una orientación más detallada, consulte la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

2. Concepto de la garantía real

19. En sentido general, una garantía real es un derecho de propiedad (*ius in rem*, distinto del dominio y de los derechos personales) sobre bienes muebles que se constituye mediante un acuerdo y que garantiza el pago u otro tipo de cumplimiento de una obligación (véanse las expresiones “garantía real” y “otorgante” en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, secc. B). La función de la garantía real es reducir el riesgo de pérdida que pueda suponer para un acreedor garantizado el impago de su deuda garantizada, facultándole para hacer valer su derecho a percibir, a título de fuente supletoria de reembolso, el valor realizable de los bienes gravados, con prelación sobre los derechos de los demás acreedores del otorgante. Por ejemplo, si una empresa toma fondos prestados contra la garantía de su equipo industrial e incumple su obligación de reembolsar el préstamo, un acreedor garantizado con una garantía real sobre ese equipo estará facultado para obtener posesión del equipo, enajenarlo y destinar el producto de la venta al pago del saldo pendiente. Al mitigar el riesgo de la pérdida resultante de un impago, el otorgante tendrá mayores posibilidades de obtener el préstamo, a menudo en condiciones más favorables.

20. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se adopta un enfoque funcional del concepto de garantía real. Con arreglo a este enfoque, el concepto

abarca cualquier tipo de derecho de propiedad sobre un bien mueble que funcione en esencia para garantizar el cumplimiento de una obligación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 101 a 112, y recomendaciones 2 y 10). Por consiguiente, el concepto no se limita a los tipos de dispositivos de garantía reconocidos convencionalmente por los distintos ordenamientos jurídicos, tales como la prenda, el gravamen o la hipoteca. Abarca todo derecho de propiedad que funcione como garantía. Por lo tanto, incluye la transmisión de bienes corporales o la cesión de bienes inmateriales en garantía, así como la retención de la titularidad por un vendedor para garantizar el pago del precio de compra de un bien o el dominio residual de un arrendador en el caso de un arrendamiento financiero (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 101 a 112, y recomendaciones 2, 8 y 9).

21. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda este enfoque funcional, integrado y global del concepto de garantía a fin de asegurar que los derechos legales de acreedores, deudores y terceros estén sujetos a un marco jurídico común independientemente de la forma de la operación, el tipo de bien gravado, el carácter de la obligación garantizada o la condición de las partes. No obstante, reconoce que podría ser necesario excluir las operaciones garantizadas relacionadas con determinados tipos de bienes gravados, o bien porque estos ya estén regulados por otra legislación del Estado promulgante (por ejemplo, el equipo aeronáutico al que hacen referencia el Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y su Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico), o porque planteen cuestiones que puedan tratarse más adecuadamente en el marco de un régimen más especializado (por ejemplo, los valores bursátiles a los que hace referencia el Convenio sobre el régimen sustantivo aplicable en materia de valores depositados en poder de un intermediario). Ahora bien, toda otra excepción (por ejemplo, las prestaciones laborales) debería definirse de forma estricta y clara en la legislación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párr. 44, y recomendaciones 4 y 7).

3. Constitución de una garantía real

22. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que se haga una distinción entre la constitución de una garantía real (validez entre el otorgante y el acreedor garantizado) y su oponibilidad a terceros (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 1 a 7, cap. III, párrs. 6 a 8, y recomendaciones 1, apartado c), 13 y 30). La razón principal para adoptar este enfoque es permitir que las partes constituyan una garantía real sobre sus bienes de manera sencilla y eficiente (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 1, apartado c), y 13).

23. Así pues, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* impone el mínimo de requisitos formales para la constitución de una garantía real. Recomienda lo siguiente: a) cabe crear una garantía real simplemente mediante un acuerdo concertado entre el otorgante y el acreedor garantizado; b) en el acuerdo se debe indicar la intención de las partes de constituir una garantía real, identificar a las partes y describir la obligación garantizada y los bienes gravados (pero no hay otros requisitos); c) el acuerdo debe haberse hecho por escrito, y únicamente ha de indicar la intención del otorgante de crear una garantía real si no va acompañado de una transmisión de la posesión efectiva del bien gravado al acreedor garantizado; y d) el

requisito de concertarlo por escrito es flexible e incluye los medios de comunicación electrónicos (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 11 a 15).

24. Al prescindir del requisito de transmitir la posesión de los bienes gravados para constituir una garantía real, el régimen de operaciones garantizadas previsto por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* permite a una empresa gravar no solo sus bienes corporales existentes sino también sus bienes inmateriales y futuros, así como la masa de bienes en circulación, incluidos, lo cual es muy importante, los créditos por cobrar y las existencias (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. II, párrs. 49 a 70, y recomendaciones 2 y 17). Con arreglo a las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, se constituye una garantía real sobre bienes futuros no bien el otorgante adquiere derechos sobre esos bienes (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 13). La Guía también permite a una empresa mantenerse en posesión de sus bienes corporales gravados y seguir utilizándolos. Gracias a este enfoque, es probable que aumente el acceso al crédito al ampliarse la gama de bienes que puede ofrecer un otorgante como garantía. Las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* confirman además que una garantía real puede utilizarse para respaldar cualquier tipo de obligación, incluidas las obligaciones futuras o indeterminadas (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 16).

25. El reconocimiento por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* de las garantías reales no posesorias también facilita el acceso del consumidor al crédito puesto que permite a los otorgantes que son también consumidores tomar posesión inmediata de los bienes adquiridos con un crédito garantizado. Sin embargo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* tiene en cuenta la necesidad de preservar los derechos del consumidor o de otras personas que puedan necesitar protección especial. Por consiguiente, recomienda que el régimen de las operaciones garantizadas no afecte a los derechos de los consumidores previstos en la legislación de protección al consumidor ni deje sin efecto los límites legales relacionados con cualquier tipo particular de bienes que puedan ser transmitidos o gravados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 10 y 11; cap. II, párrs. 56, 57 y 107; recomendaciones 2, apartado b), y 18).

26. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* también confirma que, salvo acuerdo en contrario de las partes, una garantía real se mantiene automáticamente sobre cualquier producto de los bienes gravados (y el producto del producto) sin necesidad de concertar un acuerdo especial al respecto (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 19). Este enfoque está en armonía con las expectativas de las partes (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. II, párrs. 72 a 81).

4. Oponibilidad a terceros de una garantía real

27. Con arreglo a las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, una garantía real se vuelve exigible entre las partes no bien se cumplen los requisitos reseñados más arriba. Sin embargo, no se puede constituir una garantía real en oposición a derechos adquiridos por terceros sobre los bienes gravados a menos que se satisfagan los requisitos de oponibilidad a terceros de la garantía real. El propósito de esta distinción es asegurar que la garantía real

constituida por un acuerdo privado entre las partes se dé a conocer públicamente a terceros que pudieran verse perjudicados por su existencia.

28. La inscripción de una notificación en un registro general de las garantías reales es el método principal reconocido por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* para lograr la oponibilidad a terceros de una garantía real (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 32). Si bien este es el único método de que se dispone para todos los tipos de bienes gravados, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce la existencia de otros métodos según el tipo de bien gravado.

29. En primer lugar, la desposesión del otorgante constituye un método alternativo de lograr la oponibilidad a terceros, siempre que esa desposesión sea efectiva (es decir, que no sea deducible, ficticia, supuesta o simbólica). La transmisión de la posesión de los bienes gravados al acreedor garantizado o a su representante constituye suficiente notificación práctica a los terceros de que es probable que el derecho de propiedad del otorgante sobre dichos bienes esté gravado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, secc. B, “posesión”, y recomendación 37). Dado que se requiere la desposesión física, este método de lograr la oponibilidad a terceros puede emplearse solamente en el caso de los bienes corporales de que el otorgante sea propietario en el momento de concertar el acuerdo de garantía y únicamente si, como cuestión práctica, el otorgante está dispuesto a renunciar a su posesión.

30. En segundo lugar, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que, en los casos en que el bien gravado garantice el derecho al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria o un derecho a recibir el producto de una carta de crédito, los acreedores garantizados tendrán la opción de lograr la oponibilidad a terceros tomando “control” del bien gravado en lugar de hacer la inscripción en el registro general de las garantías reales (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, secc. B, “control”, y recomendación 103)⁹.

31. En tercer lugar, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* puede aplicarse a las garantías reales sobre tipos de bienes que están sujetos a un régimen especial de inscripción registral, por ejemplo los vehículos automotores, los buques, las aeronaves y la propiedad intelectual (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 32 a 36, y recomendación 4, apartados a) y b)). En la medida en que es aplicable a las garantías reales sobre estos tipos de bienes, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que se reconozca la inscripción en el registro especial como método alternativo para lograr la oponibilidad a terceros (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 38).

32. En cuarto lugar, en los casos en que, en el momento de concertarse el acuerdo de garantía, el bien gravado esté o pueda estar incorporado a un bien inmueble de manera que forme parte de una propiedad inmobiliaria, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la garantía real pueda hacerse oponible a

⁹ Cabe observar que las garantías reales y los derechos de pago nacidos en virtud de contratos financieros regidos por acuerdos de compensación global u operaciones con divisas no están incluidos en el ámbito de aplicación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 37 a 39, y recomendación 4, apartados c) a e)). Para estos tipos de bienes, el Estado promulgante tal vez desee examinar la posibilidad de establecer normas especiales.

terceros mediante la inscripción sea en el registro general de las garantías reales o en el registro de la propiedad inmobiliaria (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 43; en lo que respecta a las consecuencias que tendría para el orden de prelación la elección de un lugar u otro para efectuar la inscripción registral, véase el párrafo 40 *infra*).

5. Prelación de una garantía real

a) Garantías reales concurrentes

33. Si se ha hecho oponible a terceros más de una garantía real constituida por el mismo otorgante sobre el mismo bien gravado, es necesario tener una norma de prelación para ordenar las garantías reales concurrentes entre sí (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párrs. 12 a 14). En los casos en que las garantías reales concurrentes se hicieron, todas ellas, oponibles a terceros mediante inscripción registral, la prelación se determina en general por el orden de inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 76, apartado a)). En los casos en que se hicieron oponibles a terceros mediante un método distinto a la inscripción, la prelación se determina en general por el orden cronológico en que se logró la oponibilidad a terceros (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 76, apartado b)). En caso de que una garantía real que se haya hecho oponible a terceros por métodos distintos de la inscripción registral (por ejemplo, por entrega del bien) compita con una garantía real que adquirió su validez frente a terceros por inscripción registral, la prelación se determina generalmente por el orden cronológico respectivo de la inscripción registral o de la oponibilidad a terceros (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 76, apartado c)).

34. Si bien estas recomendaciones proporcionan las normas básicas, un régimen moderno de las operaciones garantizadas del tipo recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconocerá, invariablemente, algunas excepciones a fin de facilitar otras prácticas comerciales y la consecución de objetivos normativos. En los párrafos siguientes se resumen las principales excepciones reconocidas por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

35. En primer lugar, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce que ha de concederse prelación especial al acreedor garantizado que financie la adquisición por el otorgante de bienes corporales (por ejemplo, bienes de consumo, equipo o existencias) o propiedad intelectual (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. X, párrs. 125 a 139, y el *Suplemento*, párrs. 181 a 183). Siempre que se cumplan los requisitos recomendados por la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* para obtener esta prelación especial (es decir, la inscripción de una notificación y, si se trata de existencias, posiblemente la notificación a los financiadores de las existencias identificados en el registro; véase la recomendación 180, variante A, apartado b), y variante B, apartado b)), la “garantía real del pago de una adquisición” tendrá prelación, en lo que respecta al valor de esos bienes, por encima de las garantías reales sobre los bienes futuros de ese tipo del otorgante que hayan sido adquiridos previamente y que se hayan inscrito en un registro o que se hayan hecho oponibles a terceros de otro modo. Este enfoque no perjudica al acreedor garantizado anterior puesto que el otorgante no habría podido adquirir esos nuevos bienes de no ser por la nueva financiación. Dar prelación a las garantías

reales del pago de una adquisición beneficia también al otorgante al brindarle acceso a fuentes diversificadas de crédito garantizado para financiar nuevas adquisiciones.

36. En segundo lugar, una garantía real sobre una suma monetaria o sobre títulos negociables o documentos negociables que se vuelva oponible a terceros mediante la transmisión de la posesión al acreedor garantizado tiene prelación sobre una garantía real que se haya hecho oponible a terceros anteriormente mediante inscripción registral (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 101, 102, 108 y 109). Esta excepción se basa en el principio de que conviene preservar la libre negociabilidad de estos tipos de bienes en el mercado.

37. En tercer lugar, cuando el bien gravado sea el derecho al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria o el derecho a recibir el producto de una carta de crédito, un acreedor garantizado que obtenga prelación al tomar “control” del bien gravado tendrá prelación sobre una garantía real anterior o posterior que se haya hecho oponible a terceros mediante inscripción registral (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, secc. B, “control”, y recomendaciones 103 y 107). Como ya se ha mencionado (véase la nota a pie de página 9 *supra*), las garantías y los derechos de pago nacidos en virtud de contratos financieros regidos por acuerdos de compensación global o de operaciones con divisas no se incluyen en el ámbito de aplicación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 37 a 39, y recomendación 4, apartados c) a e)). Los Estados promulgantes deberán establecer normas especiales de prelación en lo que respecta a estos tipos de bienes.

38. En cuarto lugar, en la medida en que el régimen de las operaciones garantizadas se aplique a las garantías reales sobre tipos de bienes muebles que estén sujetos a sistemas de registro especiales como, por ejemplo, los vehículos automotores, los buques, las aeronaves y la propiedad intelectual (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 32 a 36, y recomendación 4, apartados a) y b)), la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que se dé prelación a toda garantía real que se haya hecho oponible a terceros mediante la inscripción en el registro especial en contraposición a una garantía real inscrita en el registro general; y en el caso de que ambas garantías reales estén inscritas en el registro especial, recomienda que la prelación se determine por el orden de inscripción en dicho registro especial (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 77 y 78). Estas normas tienen por objeto preservar la fiabilidad y exhaustividad del fichero del registro especial.

39. En quinto lugar, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* adopta un enfoque similar para determinar la prelación de las garantías reales concurrentes sobre bienes incorporados a un bien inmueble. Recomendando que se dé prioridad a toda garantía real cuya notificación se haya inscrito en el registro de la propiedad inmobiliaria, con preferencia a una garantía real sobre el bien incorporado cuya notificación se haya inscrito solamente en el registro general de las garantías reales; y en los casos en que la inscripción registral con respecto a todas las garantías reales concurrentes se haya hecho en el registro de la propiedad inmobiliaria, recomienda que la prelación se determine por el orden de inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 87 y 88). Estas normas tienen igualmente por objeto preservar la fiabilidad y exhaustividad del fichero del registro de la propiedad inmobiliaria.

b) Compradores u otros cesionarios de bienes gravados

40. Por regla general, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce que todo acreedor garantizado que haya cumplido con los requisitos de la oponibilidad a terceros respecto de su garantía real tiene el “derecho a seguir” el bien gravado cuando pasa a manos de un comprador u otro cesionario del otorgante que adquiere derechos sobre el bien gravado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. II, párrs. 72 a 89, cap. III, párrs. 15, 16 y 89, y recomendación 79). A la inversa, el cesionario recibirá el bien gravado libre de una garantía real si esta no se ha vuelto oponible a terceros mediante la inscripción registral o algún otro método aun cuando dicho cesionario tenga conocimiento de la existencia de la garantía real (según la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, por “conocimiento” se entiende conocimiento real; véase la Introducción, secc. B). Este enfoque no es injusto con los acreedores garantizados, pues estos podían haberse protegido inscribiéndose en el momento debido o adoptando otras medidas para hacer que la garantía real fuera oponible a terceros. No obstante, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce varias excepciones a esta regla general. En los siguientes párrafos se resumen las principales.

41. En primer lugar, cuando un acreedor garantizado autoriza al otorgante a vender, arrendar o conceder licencias sobre un bien gravado libre de toda garantía real, dicha garantía real no afecta a los derechos del comprador, arrendatario o licenciario (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 80). Normalmente, el acreedor garantizado solo dará su aceptación una vez que se haya llegado a un acuerdo con el otorgante para que se ofrezca algún otro tipo de garantía, por ejemplo asegurando que el producto de la operación se remita directamente al acreedor garantizado.

42. En segundo lugar, un comprador, arrendatario o licenciario que adquiera un bien gravado en el curso ordinario de los negocios del otorgante lo adquiere libre de todo gravamen aun cuando el acreedor garantizado haya inscrito una notificación de la garantía real o cumplido de cualquier otro modo con los requisitos de la oponibilidad a terceros (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 81). Este enfoque es compatible con toda expectativa comercial razonable de las partes. Por ejemplo, no sería realista esperar que los compradores de bienes ofrecidos por una empresa que habitualmente vende el tipo de bienes que interesa al comprador consulten el registro antes de concertar la operación. Por lo demás, un acreedor garantizado que haya aceptado una garantía real sobre las existencias de un otorgante lo hará normalmente en el entendimiento de que el otorgante podrá enajenar sus existencias, libres de todo gravamen, en el curso normal de sus negocios. No en vano, para que el otorgante pueda obtener los ingresos necesarios para reembolsar el préstamo garantizado, sus clientes deberán sentirse legalmente seguros de que todo bien que adquieran del otorgante en el curso normal de sus negocios estará libre de todo gravamen.

43. En tercer lugar, la misma política de preservación de la negociabilidad que justifica otorgar una prelación especial al acreedor garantizado que toma posesión física de un bien gravado en la forma de dinero o documentos negociables (como un conocimiento de embarque) o títulos negociables (como un cheque) también justifica que se dé prelación a los cesionarios directos de esos tipos de bienes gravados que toman posesión física de ellos (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 101, 102, 108 y 109).

44. En cuarto lugar, como ya se ha mencionado, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* puede aplicarse a bienes que se encuentran sujetos a un régimen de inscripción registral especial, como los vehículos automotores, los buques, las aeronaves y la propiedad intelectual (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 32 a 36, y recomendación 4, apartados a) y b)). Estos registros normalmente cumplen funciones más amplias que la de simplemente dar a conocer las garantías reales sobre los bienes pertinentes; en particular, hacen constar la propiedad o la transmisión de la propiedad. Por consiguiente, en la medida en que la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se aplica a las garantías reales sobre estos tipos de bienes, recomienda que se dé prelación a los derechos del comprador u otro cesionario respecto del cual se haya hecho una inscripción en el registro especial con preferencia a la garantía real inscrita en el registro general de garantías reales; y en el caso de que la notificación con respecto a la garantía real también esté inscrita en el registro especial, se recomienda determinar el orden de prelación según el orden de inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 77 y 78).

45. En quinto lugar, se adopta un enfoque similar cuando se trata de determinar la prelación con respecto a garantías reales sobre bienes incorporados a bienes inmuebles. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que se dé prelación a los derechos del comprador u otro cesionario del bien inmueble en cuestión con respecto al cual se haya inscrito una notificación en el registro de la propiedad inmobiliaria, con preferencia a la garantía real inscrita únicamente en el registro general de garantías reales; en los casos en que la notificación con respecto a la garantía real sobre el bien incorporado también esté inscrita en el registro de la propiedad inmobiliaria, se recomienda determinar el orden de prelación según el orden de inscripción en dicho registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 87 y 88).

c) Acreedores no garantizados del otorgante

46. Una de las principales ventajas de obtener una garantía es que permite al acreedor garantizado hacer valer su derecho a reclamar el valor de los bienes gravados con preferencia a las reclamaciones de los acreedores no garantizados del otorgante. En consecuencia, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que una garantía real tenga prelación sobre los derechos de un acreedor no garantizado siempre que el acreedor garantizado haya hecho una inscripción registral o, de otro modo, haya hecho que su garantía real sea oponible a terceros antes de que el acreedor no garantizado obtenga una decisión judicial o una orden judicial provisional contra el otorgante y adopte las medidas necesarias con arreglo a alguna otra ley del Estado promulgante para adquirir derechos sobre los bienes gravados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 84). Este enfoque permite al acreedor no garantizado determinar la medida en que los bienes de sus deudores pueden estar gravados a fin de decidir si vale la pena o no obtener una decisión judicial o emprender un proceso ejecutorio judicial. Ahora bien, la norma de la prelación está sujeta a una importante reserva. Aun cuando el acreedor garantizado haya inscrito la notificación de su garantía real o logre por otros métodos la oponibilidad a terceros después que el acreedor no garantizado adquiera derechos sobre los bienes gravados de su deudor, el acreedor garantizado tendrá prelación en la medida del crédito que haya extendido por adelantado antes de haber tomado conocimiento de que el acreedor no garantizado

ha adquirido derechos sobre los bienes gravados o ha extendido crédito al otorgante con arreglo a un compromiso anterior irrevocable (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. V, párrs. 94 a 106, y recomendación 84).

47. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* examina, pero sin hacer ninguna recomendación al respecto, las medidas que debe adoptar un acreedor no garantizado para adquirir derechos sobre los bienes de su deudor de modo que tenga posibilidades de prevalecer sobre un acreedor garantizado que no haya logrado la oponibilidad a terceros en absoluto o a su debido tiempo (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. V, párrs. 94 a 106). Esto se deja al régimen de las ejecuciones judiciales del Estado promulgante. En algunos Estados, un acreedor no garantizado solo adquiere derechos sobre los bienes de su deudor una vez que se ha terminado el proceso de ejecución judicial mediante la incautación y venta y que los derechos del acreedor judicial se han incorporado al producto de la venta. En otros Estados, un acreedor no garantizado, al obtener una sentencia ejecutoria, puede conseguir el equivalente de una garantía real general sobre los bienes muebles presentes y futuros del deudor por sentencia judicial simplemente inscribiendo una notificación de la sentencia en el registro general de garantías reales. En consecuencia, los Estados promulgantes que adopten las recomendaciones generales de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* deberán tener en cuenta su régimen existente en la materia y decidir cuál sería el enfoque más apropiado.

d) El representante de la insolvencia

48. En general, los regímenes modernos de la insolvencia respetan la prelación a que tienen derecho los acreedores garantizados en virtud de otra legislación en caso de que se inicien procedimientos de insolvencia contra el otorgante. Este es el criterio recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 239), en consonancia con lo dispuesto en la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia (la “Guía sobre la Insolvencia”). De ello se desprende que, en general, un acreedor garantizado tendrá prelación sobre las reclamaciones de los acreedores no garantizados de un otorgante insolvente, siempre que haya hecho una inscripción registral o cumplido de otro modo los requisitos del régimen de operaciones garantizadas para lograr la oponibilidad a terceros antes de la iniciación del procedimiento de insolvencia. Por el contrario, si el acreedor garantizado no inscribe la notificación ni se asegura de otro modo de que su garantía real es oponible a terceros antes de la iniciación del procedimiento de insolvencia, el resultado será, por lo general, que el acreedor garantizado quedará relegado en la práctica a la categoría de acreedor no garantizado.

49. No obstante, la inscripción registral a su debido tiempo no protege a un acreedor garantizado de toda medida impugnatoria fundada en ciertas reglas generales del régimen de la insolvencia, como las que declaran la nulidad de toda cesión preferencial o fraudulenta y las que otorgan prelación a determinadas categorías protegidas de acreedores (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. XII, y recomendación 239; véase también la Guía sobre la Insolvencia, recomendaciones 88 y 188).

50. Una garantía real que era oponible a terceros en el momento de iniciarse el procedimiento de insolvencia podría perderse posteriormente, por ejemplo, porque se consiguió la oponibilidad a terceros mediante la inscripción registral y el plazo de

vigencia de esa inscripción ha vencido. Para prevenir contra este riesgo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que todo acreedor garantizado tenga derecho a iniciar las acciones necesarias con arreglo al régimen de operaciones garantizadas a fin de preservar la oponibilidad de su garantía real a terceros, aun cuando se haya iniciado un procedimiento de insolvencia (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 238). Esta recomendación tiene por objeto asegurar que ningún acreedor garantizado se vea privado de la facultad de mantener su prelación como resultado de una suspensión automática de la acción ejecutoria, que se impone normalmente a las medidas ejecutorias puestas en práctica por los acreedores al iniciarse el procedimiento de insolvencia.

51. En los casos en que el procedimiento de insolvencia adopta la forma de una reorganización, los regímenes modernos de la insolvencia suelen autorizar al otorgante insolvente a constituir una garantía real sobre los bienes de la masa de la insolvencia a fin de obtener financiación posterior a la apertura de un procedimiento (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendación 65). Con arreglo a la *Guía sobre la Insolvencia*, una garantía real de este tipo no tiene prioridad sobre ningún acreedor garantizado existente a menos que así lo hayan acordado entre sí o haya sido autorizado por el tribunal con las protecciones apropiadas para ellos (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 66 y 67).

e) Créditos privilegiados

52. Por distintas razones normativas, el régimen de operaciones garantizadas o el régimen de la insolvencia, o ambos, de un Estado pueden conceder un grado de prelación preferente a ciertas categorías concretas de acreedores no garantizados frente a los créditos de los acreedores garantizados. Entre los ejemplos típicos cabe mencionar los créditos del Estado promulgante respecto del pago de impuestos y de los empleados respecto de los pagos de sus sueldos u otras prestaciones laborales. Por otra parte, en el contexto de la insolvencia, algunos Estados apartan una parte especificada del valor de los bienes gravados, especialmente de los bienes empresariales, en favor de los acreedores no garantizados con preferencia a los acreedores garantizados. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* examina los créditos privilegiados y recomienda que, en la medida en que el Estado promulgante decida mantenerlos, estén limitados tanto en cuanto al tipo como en cuanto al monto y estén previstos en el régimen de operaciones garantizadas y el de la insolvencia, según el caso, de manera clara y precisa (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. V, párrs. 90 a 93, y cap. XII, párrs. 59 a 63, y recomendaciones 83 y 239). Hay dos razones por las cuales la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* sigue este enfoque: por un lado, la *Guía* tiene en cuenta las políticas sociales que los Estados promulgantes pueden desear poner en práctica mediante los créditos privilegiados; por otro lado, reconoce que los créditos privilegiados pueden influir en el costo y la oferta del crédito.

53. En algunos Estados puede inscribirse una notificación sobre créditos privilegiados en el registro general de las garantías reales, si bien no siempre se aplican las normas de inscripción y prelación aplicables a las garantías reales constituidas mediante un acuerdo de garantía voluntario. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* examina, pero sin hacer ninguna recomendación al respecto, la cuestión de si las notificaciones relativas a créditos privilegiados deben inscribirse y cuáles serían las consecuencias, para la prelación, de la inscripción registral (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. V, párr. 90).

(A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1) (Original: inglés)

**Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre
la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de
Trabajo sobre Garantías Reales en su 23º período de sesiones**

ADICIÓN

Índice

Párrafos

Introducción (<i>continuación</i>)	
D. Información general sobre el régimen de garantías reales y la función de la inscripción registral (<i>continuación</i>)	1-23
6. Amplio alcance operacional del registro	1-5
7. Inscripción registral y ejecución de una garantía real.	6
8. Consideraciones relativas al conflicto de leyes	7-8
9. Inscripción registral de la notificación.	9-17
10. Coordinación con los registros especiales de bienes muebles	18-20
11. Coordinación con los registros de la propiedad inmobiliaria	21-23
E. Problemas de la transición	24-33
I. Creación y funciones del registro de garantías reales	34-49
A. Observaciones generales	34-49
1. Creación del registro de garantías reales	34
2. Nombramiento del director del registro	35
3. Funciones del registro	36
4. Otras consideraciones relativas a la creación del registro	37-39
5. Condiciones de uso del registro	40-41
6. Registro electrónico o de documentos en papel	42-49
B. Recomendaciones 1 a 3	
II. Acceso a los servicios del registro	50-65
A. Observaciones generales	50-65
1. Acceso del público.	50-51
2. Días y horas de funcionamiento del registro	52-54

3.	Acceso a los servicios de inscripción registral	55-58
4.	No se exige la verificación de la identidad ni prueba de la existencia de una autorización ni el examen a fondo del contenido de la notificación	59-61
5.	Acceso a servicios de consulta	62-65
B.	Recomendaciones 4 a 10	

Introducción (*continuación*)

D. Información general sobre el régimen de garantías reales y la función de la inscripción registral (*continuación*)

6. Amplio alcance operacional del registro

a) Cesión pura y simple

1. Como ya se explicó (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54, párrs. 18 a 20), el régimen de garantías reales previsto en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* tiene un amplio ámbito de aplicación y abarca todas las operaciones consensuales que funcionan, en definitiva, para garantizar una obligación independientemente del carácter formal de la garantía real del acreedor garantizado, el tipo de bien gravado, la índole de la obligación garantizada o la condición de las partes (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 101 a 112, y recomendaciones 2 y 10).

2. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el régimen de las operaciones garantizadas (con excepción de las normas que rigen la ejecución a raíz de un incumplimiento) sea aplicable también a la cesión pura y simple de créditos por cobrar. El hecho de colocar esa cesión pura y simple dentro del ámbito de aplicación del régimen de las operaciones garantizadas no significa que las cesiones puras y simples se hayan redefinido como operaciones garantizadas; más bien, se procura con ello asegurarse de que el destinatario de una cesión pura y simple de créditos por cobrar esté sujeto a las mismas normas relacionadas con la constitución de las garantías, la oponibilidad a terceros y el orden de prelación que el tenedor de una garantía real sobre créditos por cobrar. Se asegura también de ese modo que el destinatario de una cesión pura y simple tenga los mismos derechos y obligaciones frente al deudor de créditos por cobrar que un acreedor garantizado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. I, párrs. 25 a 31, y recomendaciones 3 y 167).

3. Con arreglo a este enfoque, el cesionario, por lo general, tendrá que inscribir una notificación de su garantía en el registro de garantías reales para que la cesión sea oponible a terceros que hayan presentado demandas contra el cedente; y el orden de prelación entre las garantías de los sucesivos cesionarios o acreedores garantizados concurrentes que hayan adquirido derechos sobre los mismos créditos por cobrar del mismo cedente u otorgante se determinará por lo general según el orden en que hayan sido inscritas (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párr. 43). Este enfoque reconoce que la cesión pura y simple de créditos por cobrar no solo desempeña una función de financiación sino que crea

también el mismo problema de insuficiencia de información frente a terceros que las garantías reales sobre los créditos por cobrar. A menos que se inscriba una notificación en el registro de garantías reales como condición de la oponibilidad a terceros, un posible acreedor garantizado o cesionario u otro tercero carecería de medios eficientes para verificar si los créditos por cobrar adeudados a una empresa ya han sido sujetos a una garantía real o a una cesión. Si bien es cierto que podría indagarse entre los deudores de los créditos por cobrar, ello no resulta factible en la práctica si esos deudores no han sido notificados de la cesión o si la operación abarca no solo créditos por cobrar presentes sino también créditos por cobrar futuros en general.

b) Otras operaciones no garantizadas

4. El simple arrendamiento a largo plazo y las ventas en consignación de bienes muebles no funcionan a manera de garantía del precio de adquisición de los bienes y, por consiguiente, no pueden considerarse garantías reales que queden comprendidas dentro del ámbito de aplicación del régimen de las garantías reales previsto en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Sin embargo, plantean las mismas preocupaciones con respecto a la insuficiencia de la información frente a terceros que las garantías reales no posesorias, puesto que entrañan necesariamente una separación de la titularidad del bien (del arrendador o del consignador del bien) de su posesión efectiva (en manos del arrendatario o consignatario). Para remediar este problema, algunos Estados extienden a estos tipos de operación el régimen de operación garantizada (a excepción de las normas sobre ejecución) tal como se aplica a las garantías reales para financiar adquisiciones. Además de proporcionar información adecuada para los terceros, este enfoque disminuye también el riesgo de litigios en cuanto a si una operación en forma de arrendamiento o venta en consignación constituye funcionalmente una operación de garantía. Como tal, un arrendamiento o una venta en consignación: a) dejaría de ser oponible a terceros si no se ha hecho la inscripción registral correspondiente; o b) quedaría subordinado en el orden de prelación si el arrendador o el consignador no cumplieran con los requisitos para obtener la prelación especial concedida a las garantías reales para financiar las adquisiciones. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* examina la cuestión pero sin formular ninguna recomendación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párr. 44). Cabe observar, con todo, que el arrendador o el consignador siempre tienen el recurso de hacer una inscripción registral cautelar si tienen el temor de que su garantía se caracterice como garantía real con arreglo al criterio funcional de la garantía recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y, por consiguiente, de perder la oponibilidad frente a terceros y la prelación de su garantía real.

5. Algunos regímenes jurídicos van aún más allá y exigen la inscripción registral de una notificación con respecto a los créditos privilegiados (un examen del tema conexo de la prelación de los créditos privilegiados figura en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54, párr. 52). La razón fundamental de este enfoque es que, en ausencia de una inscripción registral, resultará normalmente difícil o imposible a los posibles acreedores determinar si existen créditos privilegiados, lo que probablemente hará aumentar la incertidumbre y, por consiguiente, desalentará la oferta de crédito garantizado. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no recomienda este enfoque. Incluso los créditos privilegiados inscritos pueden influir negativamente en la oferta de crédito garantizado y en su precio si se les otorga

prelación respecto de garantías reales inscritas con anterioridad, dado que, al reducir los créditos privilegiados el valor económico del bien para el acreedor garantizado, este tenderá a menudo a traspasar la carga financiera de su crédito al otorgante de la garantía incrementando el tipo de interés o deduciendo del préstamo ofrecido el importe estimado de los créditos privilegiados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. V, párrs. 90 a 93).

7. Inscripción registral y ejecución de una garantía real

6. Algunos ordenamientos jurídicos exigen que los acreedores garantizados inscriban una notificación en el registro general de garantías reales consignando que han iniciado o se proponen iniciar una acción ejecutoria. La finalidad de este enfoque es permitir al registro de garantías reales notificar a terceros que hayan inscrito una notificación en el registro con respecto a una garantía concurrente sobre los mismos bienes gravados todo lo relativo a la ejecución pendiente. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no recomienda este enfoque. En su lugar, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el acreedor garantizado que procura obtener la ejecución tenga la obligación de consultar el registro y enviar las notificaciones necesarias a los terceros interesados (incluidos los reclamantes concurrentes) acerca de la acción ejecutoria particular que ese acreedor garantizado se propone ejercitar (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 151). Esta notificación tiene por finalidad brindar a los terceros interesados (como un acreedor garantizado con un grado de prelación inferior al del acreedor garantizado ejecutante, un garante o un copropietario de los bienes gravados) una oportunidad de vigilar el procedimiento de ejecución, presentar propuestas en cualquier venta, o remediar el incumplimiento que dio lugar al procedimiento ejecutorio.

8. Consideraciones relativas al conflicto de leyes

7. En los casos en que una operación garantizada guarda relación con más de un Estado, los acreedores garantizados y los terceros necesitan orientaciones claras para determinar cuál es la ley nacional aplicable. Con arreglo a las recomendaciones relativas al conflicto de leyes de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, la ley aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real sobre bienes corporales es la ley del Estado en que se encuentra el bien gravado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 203). Esto significa que, en caso de que un acreedor garantizado desee asegurarse de que su garantía real sobre un bien corporal es oponible a terceros mediante la inscripción registral, deberá inscribirla en el registro del Estado donde se encuentre el bien gravado. De ello se desprende que, en caso de que los bienes corporales gravados se encuentren en múltiples Estados, será preciso hacer inscripciones en los registros de todos esos Estados. Con respecto a la constitución, la oponibilidad a terceros y la prelación de las garantías reales sobre bienes inmateriales y bienes muebles que se utilizan de ordinario en múltiples jurisdicciones, la ley aplicable será por regla general la ley del Estado en que se encuentre el otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 208). Por consiguiente, el acreedor garantizado deberá hacer las inscripciones en el registro del Estado donde se encuentra el otorgante.

8. Las reglas que se acaban de reseñar son las reglas básicas. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda distintas reglas especializadas sobre el conflicto de leyes respecto de las garantías reales sobre determinados tipos de bienes, incluidos: a) bienes que están sujetos a un régimen especial de inscripción registral; b) los créditos por cobrar nacidos de una operación relacionada con bienes inmuebles; c) garantías sobre el pago de fondos acreditados en cuentas bancarias; d) derechos a recibir el producto de una promesa independiente; y e) derechos de propiedad intelectual (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 204 a 207, 209 a 215 y 248). Así, por ejemplo, cuando el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual, la ley aplicable será, en primer lugar, la ley del Estado que protege la propiedad intelectual, si bien una garantía real que se constituya y haga oponible a terceros solo con arreglo a la ley del Estado en que se encuentra el otorgante aún puede tener validez contra el representante de la insolvencia del otorgante y los acreedores judiciales (véase el *Suplemento*, recomendación 248).

9. Inscripción registral de la notificación

9. La mayoría de los Estados han establecido registros para inscribir la titularidad de los bienes inmuebles y los gravámenes que pesan sobre ellos. Muchos Estados han establecido también registros similares para un número limitado de bienes muebles de alto valor, como buques y aeronaves. Es esencial, para la creación con éxito del tipo de registro general de las garantías reales previsto en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, que sus características, profundamente diferentes, sean comprendidas claramente.

10. En primer lugar, a diferencia de los registros catastrales, de buques o aeronaves, el registro general de garantías reales previsto en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no pretende registrar la titularidad del bien gravado descrito en la notificación inscrita, ni la transmisión de esa titularidad, ni siquiera garantizar que la persona designada como otorgante en la notificación inscrita sea el auténtico propietario del bien gravado a su nombre. El registro deja únicamente constancia fidedigna de los gravámenes que tal vez pesen sobre todo bien de la índole descrita que el otorgante posea o pueda llegar a poseer a raíz de operaciones comerciales o de hechos de los que el registro no deja constancia (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 10 a 14).

11. En segundo lugar, los registros de la propiedad suelen obligar al solicitante de la inscripción a presentar a examen o a hacer inscribir la documentación probatoria de su titularidad. Ello se debe a que la inscripción en esos registros constituye al menos prueba presuntiva de la titularidad del bien inscrito o de todo derecho real o gravamen que pese sobre dicho bien. Aunque algunos registros de garantías reales en algunos Estados exigen que se presente también la documentación que subyace a la garantía, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que los Estados adopten un sistema de inscripción registral de la notificación más que de inscripción de un documento (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 54, apartado b), y 57). Un sistema de inscripción registral de las notificaciones no exige ni que la documentación probatoria de la garantía real sea inscrita ni que sea siquiera sometida al examen del personal del registro. Bastará con hacer inscribir una notificación en la que figuren los datos básicos requeridos para alertar a todo autor de una consulta acerca de la posibilidad de que los bienes

descritos en la notificación estén gravados. Esto quiere decir que la inscripción de la notificación de una garantía real no da fe de que ese gravamen existe, sino que advierte de su posible existencia actual o futura.

12. En tercer lugar, en los Estados que adoptan el sistema de inscripción de un documento, la inscripción se considera algunas veces como condición previa para la constitución de una garantía real. Como ya se explicó (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54, párrs. 21, 22, 26 y 27), la inscripción de una notificación no tiene nada que ver con la constitución de una garantía real; esa inscripción hace que cualquier garantía real constituida mediante un acuerdo de garantía, que no conste en el registro, entre las partes sea oponible a terceros (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 32, 33 y 67).

13. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda el sistema de la inscripción de notificaciones más que la inscripción de documentos debido a que la inscripción registral de la notificación:

a) Reduce el costo de la operación para los autores de inscripciones (pues no necesitan inscribir o proporcionar pruebas de la documentación relativa a la garantía a fin de hacer la inscripción) y para los terceros que consultan el registro (pues no necesitan examinar lo que podría ser una voluminosa documentación del acuerdo de garantía para determinar si la garantía real existe sobre los bienes pertinentes);

b) Alivia la labor administrativa y de archivo requerida del personal del registro para su funcionamiento;

c) Reduce los riesgos de error (cuanto menos datos se inscriban menor será el riesgo de error en su inscripción); y

d) Ampara mejor la privacidad y la confidencialidad del acreedor garantizado y del otorgante (dado que la única información sobre una operación garantizada que está a disposición del público es la necesaria para alertar a todo autor de una consulta acerca de la posibilidad de que los bienes descritos en la notificación inscrita estén gravados).

14. Puesto que la inscripción en un sistema de inscripción registral de notificaciones no significa necesariamente que exista efectivamente una garantía real, los terceros con garantías concurrentes sobre los bienes gravados querrán pruebas, normalmente, de la existencia de un acuerdo de garantía válido entre las partes y el alcance de los bienes abarcados por dicho acuerdo. Lo mismo vale aun cuando la presunta garantía real se haya vuelto oponible a terceros por algún otro método, como la transmisión de posesión, puesto que la posesión por el acreedor garantizado putativo puede obedecer a fines distintos de la garantía.

15. Algunos Estados prevén un procedimiento por el cual un tercero con un derecho de propiedad sobre un bien gravado puede solicitar esta información directamente de la persona nombrada como acreedor garantizado en una inscripción o la persona que de alguna otra manera, afirma tener esa condición. El mismo derecho se hace extensivo a los acreedores no garantizados del otorgante para permitirles decidir si deberían conceder un crédito no garantizado y si vale la pena o no que incurran en los gastos de obtener una decisión judicial y emprender la ejecución contra los bienes del deudor. Si bien la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no formula ninguna recomendación al respecto, se deja abierta la

posibilidad al deudor de pedir al acreedor garantizado que envíe la información pertinente directamente a un tercero. Sin embargo, el deudor o el acreedor garantizado pueden no sentirse inclinados a cooperar, en cuyo caso el tercero necesitará obtener un mandamiento judicial con arreglo a otra ley.

16. Aun en los Estados que permiten a los terceros exigir la verificación de la existencia de una garantía real y su alcance directamente del acreedor garantizado, este derecho puede que no se aplique a los posibles compradores o posibles acreedores garantizados. Pueden ampararse simplemente negándose a comprar o a extender el crédito garantizado a menos que la inscripción registral relacionada con la garantía real sea cancelada o el acreedor garantizado putativo esté dispuesto a comprometerse asegurándoles que no tiene intención de hacer valer ni en el presente ni en el futuro ninguna garantía real sobre el bien objeto de su interés.

17. El otorgante también puede necesitar obtener información actualizada acerca del alcance y el valor de la garantía real invocada por su acreedor garantizado y una copia de cualquier acuerdo de garantía escrito con arreglo al cual se invoca la garantía real. En algunos Estados, el otorgante tiene derecho a pedir esta información libre de cargo, si bien generalmente se imponen límites a la frecuencia con que pueden hacerse estas peticiones a fin de desalentar las peticiones injustificadas o hechas con objeto de molestar.

10. Coordinación con los registros especiales de bienes muebles

18. De existir algún registro especial que prevea la inscripción de una garantía real sobre bienes muebles que sea oponible a terceros (como en el caso de todo registro internacional en el marco del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y su Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico), los regímenes legales modernos de las operaciones garantizadas deben regular las cuestiones que suscita la coordinación de las inscripciones registrales en los dos tipos de registro. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* y el *Suplemento* examinan detenidamente la coordinación de los registros (véanse la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párrs. 75 a 82, cap. IV, párr. 117; y el *Suplemento*, párrs. 135 a 140).

19. Una forma de coordinar los registros es mediante una oponibilidad a terceros apropiada y un régimen de prelación específico. Como ya se mencionó, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que, si bien una garantía real sobre un bien sujeto a inscripción en un registro especial puede hacerse oponible a terceros por inscripción en el registro general de las garantías reales, quede subordinada en el orden de prelación a una garantía real u otro derecho respecto de los cuales se haya inscrito una notificación en el registro especial pertinente, cualquiera que sea la fecha de registro (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54, párrs. 30 y 37, y la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 43 y 77, apartado a)).

20. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* examina también otros modos de coordinar registros, en particular el reenvío automático de una copia de la información inscrita de un registro al otro y la apertura de una vía de acceso común a los diversos registros pertinentes. Esta solución planteará dificultades técnicas para el diseño del registro general de las garantías reales si la inscripción en el registro especial ha de indexarse por bienes en vez de por otorgantes, como se hace

en el registro general de las garantías reales (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párrs. 77 a 81; véase también A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 24 a 27). La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* prevé que los Estados tal vez deseen modernizar sus diversos registros especiales. No obstante, no hace ninguna recomendación formal en cuanto a la manera en que los Estados deberían garantizar la coordinación más eficiente de los registros. Este enfoque tiene en cuenta el hecho de que los registros especiales están por lo general sujetos a un régimen distinto del régimen de las operaciones garantizadas, y sus finalidades, organización y administración varían de un Estado a otro y a menudo de un registro a otro. Aun así, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* sugiere que se aproveche la reforma del régimen de las operaciones garantizadas y el establecimiento de un registro general de garantías reales para reformar los regímenes de los registros especiales a fin de asegurar un nivel equivalente de funcionamiento moderno y eficiente, introduciendo, por ejemplo, el criterio de la inscripción de la notificación, índices basados en los deudores, y con fines de oponibilidad frente a terceros y orden de prelación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 117).

11. Coordinación con los registros de la propiedad inmobiliaria

21. En casi todos los países, si no en todos, existe un registro de la propiedad inmobiliaria. En la mayoría de esos países, el registro general de las garantías reales se distingue del registro de la propiedad inmobiliaria debido a diferencias en cuanto a: a) lo que se inscribe (es decir, un documento o una notificación); b) los requisitos de la descripción del bien gravado (es decir, si es específica o genérica); c) las modalidades de la indexación (es decir, si los índices se basan en los bienes o en los deudores; véase también A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 21 a 27) y las consecuencias jurídicas de la inscripción (es decir, constitución y oponibilidad frente a terceros).

22. No obstante, un Estado que ponga en marcha un registro general de las garantías reales tendrá que proporcionar a los posibles acreedores garantizados y terceros financiadores orientación sobre las reglas que rijan la oponibilidad a terceros y la prelación de las garantías reales sobre bienes muebles que, en el momento de constituirse la garantía real, estén incorporados a bienes inmuebles, o que pasen a estarlo posteriormente. Como ya se examinó, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que toda notificación relacionada con una garantía real sobre un bien mueble incorporado a un bien inmueble se registre ya sea en el registro general de las garantías reales o en el registro de la propiedad inmobiliaria, y que la garantía real quede subordinada en el orden de prelación a la garantía real u otro derecho con respecto al cual se haya inscrito una notificación en el registro de la propiedad inmobiliaria, sea cual sea el orden cronológico de la inscripción (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54, párrs. 30 y 37, y la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 43, 87 y 88).

23. La descripción de los bienes exigida para la inscripción de una notificación relativa a una garantía real sobre un accesorio fijo de un inmueble tal vez difiera según que la inscripción se realice en el registro de las garantías reales o en el registro de la propiedad inmobiliaria. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que, a los efectos de la inscripción en el registro de las garantías reales, un accesorio fijo de un inmueble, como cualquier otro bien gravado, sea descrito en

términos que permitan su debida identificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, apartado b)). Bastará con dar una descripción del bien mueble que se haya incorporado o se vaya a incorporar al inmueble, sin necesidad de hacer una descripción de este último. En cambio, el régimen del registro de la propiedad inmobiliaria exigirá por lo general que el bien inmueble al que esté incorporado o al que se vaya a incorporar el bien corporal sea descrito con suficiente detalle como para permitir la indexación de la notificación en el registro de la propiedad inmobiliaria.

E. Problemas de la transición

24. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* contiene un examen detenido de las diversas cuestiones que los Estados que piensan aplicar un régimen de las operaciones garantizadas basado en sus recomendaciones pueden desear tener en cuenta (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, secc. E). Entre esas cuestiones cabe mencionar el tratamiento, durante la transición, de las garantías reales constituidas con arreglo al régimen anterior, y consideraciones relativas a la elaboración de leyes y a la asimilación después de la promulgación.

25. El tratamiento durante la transición de las garantías reales vigentes constituidas con arreglo al régimen anterior es con mucho la más importante de estas consideraciones, dado que un régimen basado en las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* a menudo constituirá una desviación considerable de la normativa legal anterior del Estado promulgante.

26. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que los Estados promulgantes apliquen su régimen de las operaciones garantizadas a todas las garantías reales, incluidas las que ya existan en la fecha en que la nueva ley entre en vigor (la “fecha de entrada en vigor”). No obstante, reconoce cuatro reservas importantes.

27. En primer lugar, el régimen anterior se aplica a las cuestiones relativas a la ejecución que ya estén siendo dirimidas en el marco de un litigio o de otro procedimiento vinculante de solución de controversias iniciado antes de la fecha de entrada en vigor (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 229). No obstante, este principio no se aplica cuando las partes recurran a un procedimiento no vinculante como el de conciliación. Además, este litigio en curso con arreglo a la ley anterior no debe ser obstáculo para que el acreedor garantizado entable una acción ejecutoria conforme a la nueva ley después de la fecha de entrada en vigor (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. XI, párrs. 15 y 16).

28. En segundo lugar, la normativa legal anterior determina si una garantía real supuestamente constituida antes de la fecha de entrada en vigor se constituyó efectivamente (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 230).

29. En tercer lugar, una garantía real que haya pasado a ser oponible a terceros conforme a la normativa legal anterior conservará su eficacia hasta uno de los siguientes momentos, según cuál se dé primero: a) el momento en que deje de ser oponible en virtud de la normativa legal anterior; y b) hasta la expiración

de un plazo especificado en la ley después de la fecha de entrada en vigor (el “período de transición”) (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 231). Según este criterio, el titular de una garantía real constituida con arreglo al régimen anterior recibe un plazo de transición para cumplir con los requisitos de oponibilidad a terceros con arreglo al nuevo régimen de las operaciones garantizadas.

30. En cuarto lugar, la prelación de una garantía real estará determinada por la normativa legal anterior cuando: a) la garantía real y los derechos de todos los reclamantes concurrentes hayan nacido antes de la fecha de entrada en vigor; y b) no se haya producido ningún cambio en la prelación de esos derechos después de la fecha de entrada en vigor (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 233).

31. Si en el Estado promulgante ya existe un registro de las garantías reales sobre bienes muebles, deberán abordarse otros problemas de la transición. Si el nuevo régimen de las operaciones garantizadas abarca las garantías reales que antes estaban comprendidas en el ámbito de un registro existente, el Estado promulgante podría decidir asumir la responsabilidad de transmitir la información consignada en el fichero existente al nuevo fichero del registro. En contraste con este enfoque, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la carga de la transmisión corra por cuenta de los acreedores garantizados, ofreciéndoseles un plazo de transición (por ejemplo, un año) para hacer una inscripción o conseguir por otros medios que la garantía real sea oponible a terceros. Este enfoque se ha utilizado con considerable éxito en varios Estados (especialmente cuando ese nuevo registro es gratuito). Si se opta por esta variante, debería proporcionarse un espacio o recuadro en el formulario de inscripción para indicar que la inscripción constituye la transmisión de otra efectuada antes de la entrada en vigor del nuevo régimen de las operaciones garantizadas (para un examen más detenido de estos tipos de problemas de transición, véase el cap. XI de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*).

32. Los Estados que estén llevando a la práctica las recomendaciones contenidas en el proyecto de guía sobre el registro también tendrán que tener en cuenta las cuestiones relacionadas con el método legislativo y la redacción. Algunas recomendaciones del proyecto de guía sobre el registro reiteran recomendaciones formuladas en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* relativas a la administración del registro o a su diseño técnico. Entre esas recomendaciones cabe citar las siguientes: 7 (véanse las recomendaciones 55, apartado b), y 54, apartado d)); 11, apartado a) (véase la recomendación 70); 13 (véase la recomendación 69); 12 (véase la recomendación 67); 15 (véase la recomendación 68); 18 (véase la recomendación 55, apartados c), y d)); 23 (véase la recomendación 57); 28, apartado a) (véase la recomendación 63); 29, apartado a) (véase la recomendación 58); 29, apartado b) (véase la recomendación 64); 29, apartado d) (véase la recomendación 65); y 33 (véase la recomendación 72). Las recomendaciones restantes se refieren a cuestiones de inscripción netamente técnicas. Los Estados promulgantes deberán considerar si han de ocuparse de todas estas cuestiones en la legislación sobre las operaciones garantizadas, en el reglamento del registro, en las condiciones de uso del registro o en todos estos textos o en más de uno de ellos.

33. Los Estados promulgantes también deberán considerar los problemas de la asimilación posterior a la promulgación del nuevo régimen y, en particular, la necesidad de establecer un programa encaminado a familiarizar a los posibles usuarios del registro con su funcionamiento. Más concretamente, a fin de asegurarse de que el registro se establezca sin tropiezos y sus servicios sean utilizados por los usuarios, los Estados promulgantes deberán considerar la posibilidad de confiar a un equipo encargado de la puesta en marcha la tarea de formular programas de educación y concienciación, difundiendo el material de promoción y explicativo y organizando sesiones de capacitación. El equipo encargado de la puesta en marcha debería elaborar también instrucciones sobre la forma de consignar la información en los formularios impresos de inscripción y en las pantallas electrónicas.

I. Creación y funciones del registro de garantías reales

A. Observaciones generales

1. Creación del registro de garantías reales

34. En la mayoría de los casos, las primeras disposiciones del reglamento prevén el establecimiento del registro y reiteran brevemente que, en consonancia con su finalidad según se expone en el régimen sobre las operaciones garantizadas, la finalidad del registro consiste en recibir, almacenar y hacer accesible al público información relativa a las garantías reales sobre bienes muebles (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 1).

2. Nombramiento del director del registro

35. Por lo general, el reglamento indica, sea directamente o por remisión al régimen pertinente, la autoridad facultada para designar al director del registro, determinar sus funciones y, en general, supervisar al director del registro en el desempeño de esas funciones. A fin de asegurar la flexibilidad en la administración del registro, conviene aclarar que por director del registro se entenderá una sola persona o un grupo de personas designadas y supervisadas por el director del registro para desempeñar sus funciones (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 2).

3. Funciones del registro

36. Entre las disposiciones iniciales del reglamento puede figurar también una disposición en la cual se enumeren las diversas funciones del registro que se tratan más detenidamente más adelante en el reglamento con remisiones a las disposiciones pertinentes del reglamento en que se trata de esas funciones. Este es el enfoque recomendado en el proyecto de guía sobre el registro (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 3). La ventaja de este enfoque reside en la claridad y la transparencia en cuanto al carácter y alcance de las cuestiones tratadas detenidamente en disposiciones posteriores del reglamento. La posible desventaja es que la lista pueda no ser exhaustiva o que se interprete en el sentido de que impone limitaciones no buscadas respecto de las disposiciones detalladas del reglamento a las que se refiere la remisión. Por consiguiente, la aplicación de este enfoque exige especial cuidado de evitar omisiones y contradicciones.

4. Otras consideraciones relativas a la creación del registro

37. Es de importancia crítica que el personal técnico encargado del diseño y la puesta en marcha del registro esté familiarizado con los objetivos jurídicos y prácticos que persigue, así como con las necesidades prácticas del personal del registro y de sus posibles usuarios. Por consiguiente, es preciso establecer, desde el principio mismo del proceso de diseño y puesta en marcha, un equipo que reúna los conocimientos técnicos, jurídicos y administrativos necesarios y que comprenda las necesidades del usuario.

38. Será necesario también, desde una etapa temprana determinar si el registro será administrado internamente por una entidad estatal o en colaboración con una firma del sector privado de probada experiencia técnica y con responsabilidad financiera demostrada. Aunque el funcionamiento cotidiano del registro podría delegarse a una entidad privada, el Estado promulgante debería conservar siempre la responsabilidad de asegurar que el registro funcione conforme al marco jurídico aplicable (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 47, y recomendación 55, apartado a)). Además, para fomentar la confianza pública en el registro y prevenir la comercialización y el uso fraudulento de la información consignada en el fichero del registro, el Estado promulgante debería retener la propiedad del fichero del registro y, en caso necesario, de su infraestructura.

39. El equipo encargado del diseño deberá planificar la capacidad de almacenamiento del fichero del registro. La evaluación dependerá de que el registro tenga por fin abarcar no solo las operaciones garantizadas de los consumidores sino también las del sector comercial, y de que incluya asimismo otras operaciones, como los arrendamientos simples. En tal caso, cabe prever un volumen mucho mayor de inscripciones, por lo que se debería aumentar la capacidad de almacenamiento. En la planificación de la capacidad también se deberá tener en cuenta la posibilidad de agregar aplicaciones y características al sistema. Por ejemplo, los diseñadores tal vez deseen proporcionar suficiente capacidad para ampliar en el futuro la base de datos del registro a fin de permitir la inscripción de sentencias o de garantías reales no consensuales, o la adición de vínculos con otras bases de datos públicas, como las del registro público de sociedades u otros registros de bienes muebles o inmuebles. La planificación de la capacidad dependerá también de si la información inscrita se almacena en una base de datos informatizada o se consigna en documentos en papel. La necesidad de proporcionar suficiente capacidad de almacenamiento constituye un problema mucho menos importante si el fichero es electrónico, gracias a los recientes avances tecnológicos, que han reducido considerablemente el costo del almacenamiento (la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el registro sea electrónico “de ser posible”; véase la recomendación 54, apartado j), y los párrafos 42 a 49 *infra*).

5. Condiciones de uso del registro

40. Como ya se dijo, las cuestiones relacionadas con el registro se tratan normalmente en el régimen de las operaciones garantizadas y el reglamento del registro. También pueden tratarse en las “condiciones y requisitos de uso” del registro. Las condiciones y los requisitos de uso del registro son requisitos y condiciones del acuerdo que celebran las personas que presentan notificaciones o que realizan consultas en el fichero del registro accesible al público. Por ejemplo, las condiciones de uso del registro pueden ofrecer la oportunidad, a un usuario

frecuente del registro, de abrir una cuenta. Esto ofrecería beneficios prácticos como, por ejemplo, el rápido acceso al registro y un mecanismo simplificado para el pago de tasas. Además, al establecerse las condiciones de uso del registro debería prestarse atención a los problemas de la seguridad y la confidencialidad de la información y de los datos sobre los usuarios (como, por ejemplo, el nombre del usuario y la contraseña, u otras técnicas modernas de seguridad).

41. Sobre la base de sus condiciones de uso, algunos registros ponen a disposición de los usuarios que así lo solicitan servicios adicionales. Entre ellos pueden figurar, por ejemplo, los siguientes: a) averiguación sobre las operaciones, que permite al usuario localizar por el nombre o la cuenta información sobre las operaciones realizadas durante un período determinado; b) reimpresión del certificado de verificación, que suministra reimpresiones de la verificación relativa a una inscripción concreta; y c) informes estadísticos, que proporcionan a los encargados del diseño del registro, a los encargados de la formulación de políticas y a los académicos datos útiles (por ejemplo, en cuanto al número de inscripciones y búsquedas, gastos de funcionamiento, y tasas de inscripción y búsqueda recaudadas).

6. Registro electrónico o de documentos en papel

42. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que, de ser posible, el fichero del registro, es decir, la información de todas las notificaciones inscritas, sea electrónico en el sentido de que la información contenida en las notificaciones habrá de almacenarse en forma electrónica en una base de datos informática, es decir, el contenedor de la información (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 38 a 41 y 43 y recomendación 54, apartado j), inciso i)). Un fichero de registro electrónico es la forma más eficiente y práctica de permitir que los Estados promulgantes lleven a la práctica la recomendación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* de que el fichero del registro sea centralizado y unificado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 21 a 24, y recomendación 54, apartado e)).

43. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda también que, en lo posible, el registro sea electrónico en el sentido de que permita la inscripción electrónica directa de las notificaciones y las búsquedas por los usuarios a través de Internet o directamente por sistemas de redes, en contraposición a la presentación de notificaciones y consultas en formularios de papel (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 23 a 26 y 43 y recomendación 54, apartado j), inciso ii)). Este enfoque constituye el medio más eficaz de llevar a la práctica la recomendación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* de que el sistema debería estar diseñado de modo que reduzca al mínimo el riesgo de error humano (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, recomendación 54, apartado j), incisos iii) y iv)), puesto que se elimina así la necesidad de que el personal del registro ingrese la información contenida en el formulario impreso con la solicitud de consulta en el fichero del registro y el riesgo de error que entraña la tarea de transcripción.

44. Las inscripciones y búsquedas electrónicas directas contribuyen también a la agilización del proceso de inscripción y consulta. Cuando la información se presenta al registro en documentos en papel, los autores de la inscripción deben esperar hasta que el personal del registro haya incorporado esa información al fichero del registro

para que pueda ser consultada por terceros y la inscripción empiece a surtir efecto legal. Las consultas enviadas por correo, fax o teléfono también causan demoras, porque el interesado tiene que esperar a que un empleado del registro haga la consulta en su nombre y le comunique los resultados.

45. Además de eliminar estas demoras y de reducir el riesgo de error humano, un sistema de registro en que los autores de inscripciones y consultas tengan la posibilidad de incorporar directamente por vía electrónica la información al fichero del registro tiene las siguientes ventajas:

- a) Una reducción muy considerable del personal y de los gastos diarios de funcionamiento del registro;
- b) Una reducción de las oportunidades de conducta fraudulenta o corrupta del personal del registro;
- c) Una reducción correspondiente de la posible responsabilidad del registro frente a los usuarios que pudieran sufrir pérdidas debido a que el personal del registro no hubiera anotado la información consignada en la inscripción o los criterios de consulta o lo hubiera hecho de forma incorrecta; y
- d) Acceso del usuario a los servicios de inscripción y de consulta fuera de los horarios de atención al público del registro.

46. Si se adopta ese enfoque, el registro debería diseñarse de modo que permitiera a los usuarios hacer inscripciones registrales y realizar consultas desde cualquier computadora privada, o desde las computadoras instaladas en las sucursales del registro u otras oficinas. Además, debido al costo reducido del acceso electrónico directo, las condiciones de acceso a los servicios del registro deberían permitir que los proveedores privados de servicios que actúen como terceros presten servicios de inscripción y consulta a las partes interesadas.

47. Si el fichero del registro está informatizado, las especificaciones del equipo y los programas informáticos deberán ser estrictas y emplear mecanismos de seguridad que reduzcan al mínimo el riesgo de deterioro de los datos, los errores técnicos y el fallo de los mecanismos de seguridad. Aun en los registros de documentos en papel, deberían adoptarse medidas para garantizar la seguridad e integridad del fichero del registro, si bien es cierto que esto mismo se logra de manera más eficiente y fácil si el fichero del registro es electrónico. Además de los programas de control de la base de datos, será necesario elaborar programas informáticos para gestionar las comunicaciones de los usuarios, las cuentas de los usuarios, los pagos de tasas y la contabilidad financiera, las comunicaciones entre computadoras y la reunión de datos estadísticos.

48. Será necesario asimismo evaluar las necesidades de equipo y programas y decidir qué conviene más, si elaborar internamente los programas informáticos, encomendando la tarea al equipo encargado de la ejecución, o adquirirlos a proveedores privados. Para tomar una decisión al respecto, el equipo deberá investigar si existen productos comerciales que puedan adaptarse fácilmente a las necesidades del Estado promulgante. Es importante que el creador o proveedor de los programas informáticos tenga conocimientos de las especificaciones del equipo que haya de ser suministrado por un tercero, y viceversa.

49. También deberá tenerse en cuenta si el registro ha de diseñarse para proporcionar una interfaz electrónica con otras bases de datos estatales. Por ejemplo, en algunos Estados, los autores de una inscripción pueden consultar el registro comercial o de las empresas mientras efectúan una inscripción para verificar e ingresar automáticamente la información sobre el identificador del otorgante o del acreedor garantizado (para un examen de la cuestión de la correspondencia electrónica de los nombres, véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párr. 58).

B. Recomendaciones 1 a 3

[Nota al Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las recomendaciones 1 a 3, tal como figuran en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.5. El Grupo de Trabajo quizá desee observar también que, por razones de economía, las recomendaciones no se han incluido en el presente documento en esta etapa, pero se incluirán en el texto definitivo.]

II. Acceso a los servicios del registro

A. Observaciones generales

1. Acceso del público

50. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que cualquier persona pueda inscribir una notificación de una garantía real existente o de existencia potencial o efectuar una búsqueda en el fichero del registro accesible al público (no en los archivos; véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 25 a 30, y la recomendación 54, apartados f) y g)). Este enfoque concuerda con uno de los principales objetivos de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, que es aumentar la seguridad y la transparencia (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 25, y recomendación 1, apartado f). Dada la importancia de garantizar el acceso del público a los servicios del registro, este principio debería establecerse en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 5).

51. El acceso del público se facilita si el registro está diseñado de forma de permitir que los usuarios remitan notificaciones y realicen búsquedas electrónicamente, sin necesidad de la asistencia ni la intervención del personal del registro. Como ya se vio (véanse los párrafos 42 a 49 *supra*), la inscripción registral de formularios de papel entraña mayores costos, demoras y posibles errores y responsabilidad del registro.

2. Días y horas de funcionamiento del registro

52. El enfoque de los días y horas de funcionamiento del registro que se recomienda en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* depende de la medida en que el registro haya sido concebido para permitir la inscripción y la consulta electrónica directas por los usuarios o si hace falta presentarse en persona a la oficina del registro. En el primer caso, el registro debería ser accesible a toda hora, salvo durante los breves lapsos necesarios para los servicios de mantenimiento; en el segundo caso, debería estar abierto al público con un horario compatible con las

necesidades de los usuarios potenciales del registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 42 y recomendación 54, apartado I)). En vista de la importancia de esta cuestión para los usuarios, debería tratarse en el reglamento o en las directrices administrativas publicadas por el registro (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 5).

53. En los casos en que el registro preste servicios mediante una oficina tradicional, los días y horas de funcionamiento mínimos deberían ser los días hábiles y horarios de oficina normales en el Estado promulgante. En la medida en que el registro exija o permita la inscripción de notificaciones en formularios impresos, el registro debería procurar garantizar que la información se ingresara en el fichero del registro y se pusiera a disposición de los autores de consultas en el mismo día hábil en que se reciba la notificación impresa en el registro. Los formularios de consulta impresos también deberían procesarse el mismo día en que se recibieran. Para lograr este objetivo, el plazo límite para presentar notificaciones o formularios de consulta impresos puede fijarse independientemente del horario de oficina. Por ejemplo, en el reglamento o las directrices administrativas del registro podría establecerse que, si bien la oficina del registro está abierta de las 9.00 a las 17.00 horas, todos los formularios deberán recibirse antes de determinada hora (por ejemplo, las 16.00 horas), de modo que el personal del registro tenga tiempo suficiente para consignar la información contenida en las notificaciones en el fichero del registro o para realizar una búsqueda. Otra posibilidad sería que la oficina del registro siguiera aceptando notificaciones impresas durante todas las horas de oficina pero que fijara una hora de “cierre”, tras la cual la información contenida en las notificaciones recibidas no se podría ingresar en el fichero del registro, ni se podrían realizar búsquedas, hasta el siguiente día hábil. Un tercer enfoque sería que el registro estableciera que la información se ingresara en el fichero del registro o se llevara a cabo una búsqueda dentro de un número determinado de horas de oficina tras la recepción de la notificación o la solicitud de consulta.

54. El reglamento del registro o las directrices administrativas podrían enumerar también ya sea de manera exhaustiva o indicativa las circunstancias en que el acceso a los servicios del registro podría quedar interrumpido transitoriamente. Una lista exhaustiva daría mayor certeza pero existe el riesgo de que no cubra todas las circunstancias posibles. Una lista indicativa proporcionaría mayor flexibilidad pero menor certeza. Entre las circunstancias que podrían justificar una suspensión de los servicios del registro podría figurar cualquier acontecimiento que hiciera imposible o poco práctico proporcionar a los usuarios acceso a los servicios del registro (como razones de fuerza mayor debidas, por ejemplo, a incendio, inundación, terremoto o guerra o, en los casos en que el registro proporcione a los usuarios acceso electrónico directo a sus servicios, fallos de funcionamiento de Internet o de la conexión a redes).

3. Acceso a los servicios de inscripción registral

55. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el registro esté obligado a aceptar una notificación inicial de una garantía real presentada para su inscripción (a diferencia de una notificación de modificación o de cancelación, cuya aceptación está sujeta a requisitos distintos) si: a) se presenta en el medio de comunicación autorizado (es decir, en el formulario impreso o electrónico prescrito);

b) va acompañada del pago de la tasa de inscripción autorizada, si procede; y c) proporciona el identificador del otorgante así como la restante información que debe consignarse en la notificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 54, apartado c) y A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 53 y 54).

56. Además, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el registro esté obligado a pedir y mantener una constancia de la identidad del solicitante de la inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 55, apartado b) y párrs. 57 a 59 *infra*). Este requisito adicional se incluye a modo de salvaguardia contra el riesgo de que una inscripción no haya sido autorizada por la persona identificada como otorgante en una notificación inscrita. El hecho de exigir que el registro solicite y haga constar la identidad del solicitante de la inscripción permite que el otorgante designado sepa a quién dirigirse para exigir la modificación o cancelación de una inscripción no autorizada. A fin de facilitar el proceso de inscripción, la prueba de la identidad requerida del autor de una inscripción debería ser la generalmente aceptada como suficiente en las operaciones comerciales habituales del Estado promulgante (por ejemplo, un permiso de conducir u otro documento oficial expedido por el Estado); y el registro no debería tener derecho u obligación alguna de confirmar la prueba de la identidad presentada por el solicitante de la inscripción. También debería darse a los autores de inscripciones la opción de establecer una cuenta de usuario que les proporcione claves de acceso seguras y especiales para transmitir notificaciones al registro. Esto facilitaría el acceso de los usuarios frecuentes (como las instituciones financieras, los vendedores de automóviles, los abogados y otros intermediarios), ya que solo deberían presentar la prueba exigida de su identidad una sola vez al abrir la cuenta.

57. Para aplicar estas recomendaciones, el reglamento debería disponer que toda persona tenga derecho a acceder a los servicios de inscripción del registro, siempre que: a) utilice el formulario de notificación prescrito; b) acredite su identidad de la manera prescrita por el registro; y c) haya abonado, o haya adoptado medidas para abonar, todas las tasas (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 6). El reglamento debería disponer además que el registro pueda rechazar la inscripción de una notificación si esta no contiene la información requerida en el espacio previsto para ese tipo de información o si la información consignada es ilegible (para la información requerida en una notificación inicial y en una notificación de modificación o de cancelación, véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párr. 50, A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párr. 4 y el proyecto de guía sobre el registro, recomendaciones 23, 30 y 32).

58. Cuando se presenten notificaciones incompletas o ilegibles en formularios impresos, necesariamente se producirá alguna demora entre el momento de la recepción del formulario por el registro y la comunicación de su rechazo y las razones de este al solicitante de la inscripción. No obstante, en un sistema de registro que permita que los autores de inscripciones y las personas que realicen consultas presenten directamente al registro por vía electrónica información relativa a las inscripciones, el sistema debería estar diseñado de manera tal que rechace automáticamente la presentación de inscripciones incompletas o ilegibles e indique las razones para ello en la pantalla electrónica.

4. No se exige la verificación de la identidad ni prueba de la existencia de una autorización ni el examen a fondo del contenido de la notificación

59. Como ya se mencionó (véase el párr. 56, *supra*), la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que el registro esté obligado a pedir y mantener una constancia de la identidad del solicitante de la inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 48, y la recomendación 55, apartado b)). Para facilitar el proceso de inscripción, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda además que el registro no esté obligado a verificar la prueba de su identidad ofrecida por el solicitante de la inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 54, apartado d)). Esta recomendación debería incorporarse al reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 7, apartado a)).

60. Además, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la inscripción de una notificación no tenga validez a menos que el otorgante la haya autorizado por escrito. No obstante, para evitar demoras y gastos para los autores de las inscripciones, la prueba de la autorización del otorgante no es una condición previa para acceder a los servicios del registro. Antes bien, la autorización del otorgante puede concederse antes o después de la inscripción, y un acuerdo de garantía por escrito será suficiente para constituir la autorización (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 106, y la recomendación 71). Esta recomendación debería incorporarse al reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 7, apartado b)).

61. Una vez que el solicitante de la inscripción ha cumplido con los requisitos descritos *supra* para obtener acceso a los servicios del registro, este no tiene derecho a rechazar la notificación. Por consiguiente, el reglamento debería confirmar que el registro no está obligado a realizar un examen a fondo del contenido de la inscripción (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 7, apartado c)). Esto no significa que la notificación inscrita sea necesariamente válida legalmente. El solicitante de la inscripción es responsable de los errores u omisiones que pueda cometer en la información registral presentada por él al registro (respecto de los tipos de errores u omisiones que pueden dejar sin efecto una notificación inscrita, véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3, párrs. 17 a 29). Si el registro tuviera que examinar la notificación y confirmar su validez, el resultado sería una multiplicación de las demoras, gastos y posibles errores, lo cual sería contrario al tipo de registro eficiente que se prevé en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Por lo tanto, el reglamento debería confirmar también que no es responsabilidad del registro velar por que la información de una notificación se consigne en el espacio previsto y sea completa, precisa y jurídicamente suficiente (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 7, apartado c)).

5. Acceso a servicios de consulta

62. Invocando razones de privacidad, algunos Estados exigen que las personas que realizan consultas proporcionen motivos justificables para realizar una búsqueda. A fin de facilitar el acceso del público a los servicios de consulta del registro, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que no se exija a un usuario que justifique las razones de su consulta (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 54, apartado g)). El hecho de exigir a los autores de búsquedas que justifiquen los motivos de su consulta socavaría la eficiencia del

proceso de búsqueda, dado que el registro tendría que capacitar a sus empleados para desempeñar esta función y tendría que examinar las razones dadas y determinar si son suficientes para justificar o no la consulta. Según qué razones se considerasen aceptables, el acceso igualitario del público a la información del registro podría verse entorpecido, dado que algunos autores potenciales de búsquedas tal vez no tengan la información de que disponen otros. Para tener debidamente en cuenta la necesidad de proteger la privacidad del otorgante, la inscripción debería hacerse con la autorización de este (véase el párrafo 60 *supra*) y debería establecerse un procedimiento judicial o administrativo ágil que permitiera a los otorgantes cancelar o modificar en forma rápida y económica toda notificación no autorizada o errónea (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 38 a 41). Las preocupaciones relacionadas con la identidad del acreedor garantizado pueden atenderse permitiendo que las inscripciones sean realizadas por el representante del acreedor garantizado y en representación de este. En todo caso, la privacidad no preocupa tanto en el marco del enfoque de inscripción de la notificación recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, dado que las notificaciones inscritas proporcionan únicamente la información mínima necesaria para alertar a alguien que consulte el registro de que puede existir una garantía real sobre el bien que se describe en la notificación (véanse los párrafos 9 a 11 *supra*).

63. Por consiguiente, el reglamento debería disponer que toda persona tenga derecho a consultar el fichero del registro accesible al público, siempre que esa persona presente la solicitud de consulta en el formulario prescrito y haya abonado, o haya adoptado medidas para abonar, todas las tasas prescritas (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 9). La disposición recomendada hace referencia al fichero del registro “accesible al público” porque las inscripciones cuyo período de vigencia haya expirado o que se hayan cancelado deben retirarse del fichero accesible al público y archivarse (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 44 y 45, y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 20).

64. Al igual que en el caso de las inscripciones incompletas o ilegibles, el reglamento debería prever que el registro pueda rechazar una solicitud de consulta si su autor no suministra un criterio de consulta de una manera legible en el espacio previsto, y que dé motivos del rechazo de inmediato o tan pronto como sea factible (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 10). En los sistemas de registro que permiten que los autores de las inscripciones presenten electrónicamente solicitudes de consulta al registro, el programa informático debería diseñarse de manera tal que impida automáticamente la presentación de solicitudes de consulta que no incluyan un criterio de búsqueda legible en el espacio previsto, indicando los motivos en la pantalla electrónica.

65. A diferencia de lo que ocurre con el enfoque adoptado para los autores de inscripciones (véanse los párrafos 55 a 57 *supra*), la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no requiere que se exija y anote en el registro la identidad del autor de una consulta como condición previa para presentar una solicitud de consulta (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 55, apartado b)). Dado que el autor de una consulta solo estará recuperando del fichero del registro información que figura en notificaciones inscritas, no existe una preocupación equivalente por proteger al otorgante de inscripciones no autorizadas. Por consiguiente, la prueba de la identificación solo deberá solicitarse a los autores de

consultas si ello resulta necesario a los efectos del cobro de tasas de consulta, si procede.

B. Recomendaciones 4 a 10

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las recomendaciones 4 a 10, tal como se reproducen en el documento A/CN.9/WG.VI/ WP.54/Add.5. El Grupo de Trabajo quizá desee observar también que, por razones de economía, las recomendaciones no se han incluido en el presente documento en esta etapa, pero se incluirán en el texto definitivo.]

(A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2) (Original: inglés)

**Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre
la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de
Trabajo sobre Garantías Reales en su 23º período de sesiones**

ADICIÓN

Índice

	<i>Párrafos</i>
III. Inscripción registral	1-49
A. Observaciones generales	1-49
1. Momento de validez de la inscripción de una notificación	1-6
2. Plazo de validez de la inscripción de una notificación	7-15
3. Momento en el que podrá inscribirse una notificación	16-18
4. Suficiencia de una notificación única	19-20
5. Organización y recuperación de las notificaciones inscritas basadas en el otorgante	21-23
6. Organización y recuperación de las notificaciones inscritas basadas en el número de serie	24-27
7. Preservación de la integridad y seguridad del fichero del registro	28-33
8. Responsabilidad del registro	34-37
9. Obligación del registro de enviar copia de una notificación inscrita a su autor	38-40
10. Obligación del acreedor garantizado de enviar al otorgante una copia de la notificación inscrita	41-42
11. Modificación de la información consignada en el fichero del registro accesible al público	43
12. Retirada y archivo de la información del fichero del registro accesible al público	44-45
13. Idioma de las notificaciones y las solicitudes de consulta	46-49
B. Recomendaciones 11 a 22	
IV. Inscripción de notificaciones iniciales	50-71
A. Observaciones generales	50-71
1. Introducción	50-51
2. Información sobre el otorgante	52-71

III. Inscripción registral

A. Observaciones generales

1. Momento de validez de la inscripción de una notificación

1. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que la inscripción de una notificación surta efecto solo a partir del momento en que la información consignada en esa notificación se inscriba en el fichero del registro, de modo que pueda encontrarla toda persona que la consulte, y no a partir del momento en que la información contenida en la notificación sea recibida por el registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 102 a 105, y la recomendación 70).

2. En vista de la importancia del momento de validez de la inscripción registral para determinar la oponibilidad a terceros y la prelación de la garantía real a que se refiere, esta recomendación debería incluirse en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 11, apartado a)). Además, el reglamento debería disponer que el momento de validez de la inscripción (es decir, la fecha y hora a partir de las cuales puede consultarse la notificación) conste en el fichero el registro relativo a esa notificación (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 11, apartado b)).

3. Como ya se señaló, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que, en lo posible, se cree un fichero informatizado del registro. Si la información consignada en las notificaciones se incorpora a un fichero de ese tipo, el programa informático del registro debería estar concebido para garantizar que el público pueda consultarla inmediata o casi inmediatamente después de su incorporación. Con los adelantos de la tecnología moderna, ello no debería suponer ningún problema. De ese modo se eliminaría efectivamente toda demora entre la incorporación al registro de la información consignada en una notificación y el momento en que el público pudiera consultarla.

4. En los sistemas de registro que permiten a los autores de la inscripción transmitirles información directamente por vía electrónica, estos ejercen control sobre el momento en que adquiere validez su inscripción y la eficiencia del procedimiento. En cambio, en aquellos sistemas que permiten o exigen presentar en formato impreso la información que se desee inscribir, los autores de la inscripción deben recurrir al personal del registro para que la consigne en el fichero. Habida cuenta de la importancia del momento y el orden de inscripción para la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real, en el reglamento se debería disponer que el registro incorporase en el fichero la información consignada en notificaciones impresas según el orden en que se le presenten (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 11, apartado c)).

5. En un sistema de registro híbrido que permitiera presentar notificaciones en formato impreso y electrónico, esa recomendación no aseguraría necesariamente la prelación de un acreedor garantizado que hubiese presentado al registro una notificación impresa antes de que un acreedor concurrente presentara la suya por vía electrónica. Por ejemplo, la notificación impresa podría recibirse a las 08.00 horas y el personal del registro podría incorporarla al fichero para que quedase abierta a las consultas a las 08.30 horas, pero un acreedor garantizado concurrente podría

ingresar a las 08.05 horas una notificación electrónica que podría consultarse a las 08.10 horas. En el supuesto de que la prelación de uno respecto del otro estuviese determinada por la regla general basada en el orden de inscripción, el segundo tendría prelación, porque su notificación habría sido la primera en quedar abierta a las consultas y por ello la primera en inscribirse. En los sistemas que adoptan ese enfoque híbrido, se debería advertir sobre esa posible desventaja a los autores de inscripciones que optaran por utilizar notificaciones impresas.

6. El reglamento debería disponer que el registro asignara un número de inscripción único a toda notificación inicial (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 12). Ello es necesario para que en el fichero del registro se establezca un nexo entre la notificación inicial relativa a una garantía real y toda notificación posterior de modificación o cancelación relacionada con dicha garantía real, a fin de que esa notificación pueda recuperarse y aparezca en los resultados de una búsqueda (la necesidad de que el autor de una inscripción señale el número de inscripción de la notificación inicial a que se refiere la modificación o cancelación se examina en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 4 y 24).

2. Plazo de validez de la inscripción de una notificación

7. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que los Estados promulgantes adopten uno de dos enfoques propuestos respecto del plazo de vigencia (o duración de la validez) de una notificación inscrita en el registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 87 a 91, y recomendación 69).

8. Con arreglo a la variante A, todas las notificaciones inscritas tienen un plazo de vigencia uniforme fijado por la ley. De ello se desprende que, en los casos en que la operación garantizada a que se refiere la notificación inscrita tenga una duración mayor, el acreedor garantizado deberá asegurarse de que el período de vigencia se prorrogue antes de que venza el plazo legal. Este enfoque da certeza en cuanto al plazo de vigencia de una notificación inscrita, pero limita la flexibilidad de su autor para ajustar ese plazo a la duración probable de la operación financiera garantizada.

9. Con arreglo a la variante B, el solicitante de la inscripción puede fijar por cuenta propia el período de vigencia deseado, con la posibilidad de prorrogarlo por otro período que él mismo fije, mediante la inscripción de una notificación de modificación. En los ordenamientos jurídicos que adoptan este último enfoque, puede resultar conveniente basar las tasas de inscripción en una tarifa de escala móvil que esté en función del período establecido por el solicitante de la inscripción, a fin de desalentar la fijación de plazos excesivos que no correspondan a la duración prevista de los acuerdos de garantía correspondientes (con un margen de tiempo suplementario para tener en cuenta toda demora en el pago de una obligación garantizada).

10. Los Estados promulgantes deberían incorporar una de esas dos variantes a su régimen de las operaciones garantizadas y al reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 13 variantes A y B). Otra posibilidad sería que adoptaran una tercera variante, que es una mezcla de las dos primeras. Conforme a ella, el solicitante de la inscripción tendría derecho a elegir el plazo de vigencia de la notificación inscrita, cuya duración estaría sin embargo sujeta a un límite máximo, para desalentar la fijación de plazos excesivos (véase la *Guía sobre las*

Operaciones Garantizadas, cap. IV, párr. 88, y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 13, variante C).

11. Si un Estado elige la variante A, debería concebir el sistema de registro de manera que permitiera al solicitante de la inscripción reducir el plazo legal de validez de una notificación inscrita, si se previera que la duración real del acuerdo de garantía fuera menor que la del plazo legal establecido. La razón es que el solicitante de la inscripción está obligado, en cualquier circunstancia, a inscribir una notificación de cancelación tras liquidarse la obligación garantizada y quedar sin efecto el acuerdo de garantía (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 38 a 41).

12. En los Estados que adopten las variantes B y C, el plazo de vigencia de la notificación inscrita es un elemento obligatorio de la información que se debe incluir en la notificación, lo que significa que esta sería rechazada si no señalara en el espacio previsto su plazo de vigencia (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3, párr. 14).

13. Si el Estado promulgante eligiera la variante B o la C, sería conveniente diseñar el formulario de la notificación prescrito de forma que el solicitante de la inscripción pudiese indicar con facilidad el plazo de vigencia deseado sin exponerse al riesgo de cometer por inadvertencia un error de limitar sus posibilidades a la fijación de plazos contados por años enteros a partir de la fecha de inscripción.

14. Con independencia de que se elija la variante A, B o C, se aplicarán al cálculo del período de vigencia de una notificación inscrita en el registro las normas generales previstas en el derecho del Estado promulgante para establecer los plazos, a menos que el régimen de las operaciones garantizadas disponga otra cosa. Por ejemplo, esas normas generales del derecho del Estado promulgante podrán disponer que cuando el cálculo se realice a partir del día de la inscripción o del aniversario de ese día, el año comenzará a correr a partir del principio de ese día.

15. Sea cual fuere el enfoque que adopte el Estado promulgante para determinar el plazo de vigencia de una inscripción, conforme a las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, la oponibilidad a terceros de una garantía real se pierde al vencer el plazo de vigencia de esa inscripción, a menos que: a) la garantía real se haga oponible a terceros antes de vencerse el plazo por otro método autorizado para ese tipo de bien gravado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 46); o b) se inscriba una notificación de modificación por la que se prorrogue el plazo de vigencia de la inscripción. Si bien la oponibilidad a terceros de esa garantía real podría restablecerse mediante la inscripción registral de una nueva notificación, la garantía real sería eficaz frente a terceros solo a partir del momento de efectuarse la nueva inscripción. En consecuencia, por regla general estaría subordinada a los acreedores garantizados inscritos con anterioridad y a los acreedores garantizados que con anterioridad hubieran hecho sus garantías reales oponibles a terceros por un método distinto de la inscripción registral (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 47 y 96, y el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 25 a 27).

3. Momento en el que podrá inscribirse una notificación

16. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda autorizar que pueda inscribirse una notificación antes de que se constituya una garantía real o se

celebre un acuerdo de garantía; ello se denomina generalmente “inscripción anticipada” (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 98 a 101, y recomendación 67). Esa norma podrá aplicarse a una notificación inicial o de modificación (porque, en principio, ambos tipos de notificación pueden inscribirse con antelación), pero no a una notificación de cancelación (porque normalmente esta solo puede inscribirse tras fracasar las negociaciones). Normalmente, dicha regla figuraría en el régimen de las operaciones garantizadas. Sin embargo, según fueran las prácticas legislativas del Estado promulgante, podría incluirse en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 14).

17. Como ya se explicó (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54, párr. 27), la inscripción registral ni crea una garantía real ni es necesaria para constituir la (véase también la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 33). Por consiguiente, mientras no se celebre el acuerdo de garantía y no se cumplan todos los demás requisitos para la constitución de una garantía real, el acreedor garantizado podrá verse frustrado por un tercero concurrente, por ejemplo, el comprador que adquiera derechos sobre los bienes gravados en el lapso que medie entre la inscripción anticipada y la constitución de la garantía real. Sin embargo, en general la inscripción registral asegurará al acreedor garantizado, una vez constituida la garantía real, su prelación respecto de otro acreedor garantizado que inscriba una notificación posterior, con independencia del orden de constitución de las garantías reales concurrentes (A/CN.9/WG.VI/WP.54, párr. 33).

18. Si las negociaciones fracasan después de efectuada la inscripción registral, o si por cualquier otra razón no se concierta un acuerdo de garantía entre las partes, la calificación crediticia de la persona que figure como otorgante en la inscripción registral podrá verse afectada por la existencia de esa inscripción registral, a menos que se cancele. Para hacer frente a esta situación, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que, si el potencial acreedor garantizado no cancela su inscripción registral, el Estado promulgante entable un procedimiento judicial o administrativo sumario para que el otorgante haga cancelar esa inscripción en caso de que su autor omita hacerlo o se niegue a ello (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72, apartado a), recomendaciones 54, apartado d) y 72, apartados b) y c), así como el documento A/CN.9/WG.VI/WP.52/Add.4, párrs. 38 a 41; y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 33).

4. Suficiencia de una notificación única

19. En un sistema de inscripción registral de notificaciones como el que se prevé en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 10 a 14, y recomendación 57, así como el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrs. 9 a 17, y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 21), no hay razón por la que una notificación única no baste para obtener la oponibilidad a terceros de garantías reales presentes o futuras nacidas de varios acuerdos de garantía entre las mismas partes y sobre los bienes señalados en esa notificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 68). Exigir que por cada acuerdo de garantía haya una notificación ocasionaría gastos innecesarios y dificultaría que el acreedor garantizado pudiera reaccionar con flexibilidad ante las posibles fluctuaciones de las necesidades financieras del otorgante y sin temor a perder la prelación que le correspondería en

virtud de la inscripción inicial. Por consiguiente, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que la inscripción de una notificación única se considere suficiente para lograr la oponibilidad a terceros de una o más garantías reales, con independencia de que existan en el momento de inscribirse o se constituyan después, y de si nacen o no de uno o más acuerdos de garantía entre las mismas partes (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 68). Normalmente, esta regla figuraría en el régimen de las operaciones garantizadas. Sin embargo, según sean las prácticas legislativas del Estado promulgante, podría incluirse o reiterarse en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 13).

20. Cabe subrayar que al inscribirse una notificación se logra la oponibilidad a terceros de garantías reales nacidas de varios acuerdos de garantía solo en la medida en que la descripción de los bienes gravados que figure en esa notificación corresponda a su descripción en cualquier acuerdo de garantía nuevo o enmendado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 63). De lo contrario, la inscripción registral no cumpliría la función de señalar a la atención de los terceros que hicieran consultas la posible existencia de una garantía real. Por consiguiente, y en la medida en que un acuerdo de garantía concertado entre las partes se refiriese a otros bienes, que no se hubiesen señalado en la notificación inicial, haría falta una nueva notificación o una modificación de la inicial, y la oponibilidad a terceros y la prelación de la garantía real sobre esos nuevos bienes tendrían validez solo a partir del momento de la inscripción registral de la nueva notificación o modificación.

5. Organización y recuperación de las notificaciones inscritas basadas en el otorgante

21. Las inscripciones en un registro de la propiedad inmobiliaria se organizan y recuperan habitualmente por remisión a un identificador alfanumérico, u otro análogo, correspondiente al inmueble de que se trate (por ejemplo, su dirección física). Suele adoptarse el mismo enfoque en los registros de determinados bienes muebles, como los de embarcaciones o aeronaves. Por ejemplo, en el registro internacional establecido en virtud del Convenio de Ciudad del Cabo y su Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico se utiliza el número de serie asignado por el fabricante de la aeronave como criterio principal de indexación y búsqueda.

22. En contraposición con ese enfoque, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que el criterio principal de indexación a efectos de búsqueda y recuperación de las notificaciones inscritas sea el identificador del otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 31 a 36, y recomendación 54, apartado h)). Esta recomendación se basa en dos consideraciones. En primer lugar, casi ninguna de las categorías de bienes muebles dispone de un identificador lo bastante singular para permitir una búsqueda útil basada en los bienes. En segundo, la indexación y la búsqueda basadas en el otorgante posibilitan que toda garantía real sobre los bienes futuros y la masa de bienes circulantes del otorgante, como el inventario y los créditos por cobrar, se haga oponible a terceros mediante una sola inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 68). A fin de aplicar esta

recomendación, el Estado promulgante debería incorporarla al reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 14).

23. Aunque la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se refiere a la indexación de la información contenida en el fichero del registro, técnicamente la indexación no es la única forma de organizar la información de una base de datos para que pueda consultarse. Por consiguiente, la regla debería redactarse de manera que permitiera actuar con flexibilidad en este aspecto al diseñar el registro (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 16).

6. Organización y recuperación de las notificaciones inscritas basadas en el número de serie

24. La indexación y búsqueda basadas en el otorgante tienen una desventaja en el contexto concreto de las operaciones del tipo que con frecuencia se denomina “el problema A-B-C-D”. Supóngase, por ejemplo, que el otorgante B, tras otorgar una garantía sobre su automóvil en favor de A, vende ese automóvil a C, quien a su vez se propone venderlo u otorgar una garantía sobre él a D. En el supuesto de que D no sepa que C ha adquirido dicho bien del otorgante inicial B, D consultará el registro utilizando como criterio de búsqueda el identificador de C. A menos que A enmiende su inscripción registral a fin de agregar como garante a C, o inscriba en el registro una nueva notificación en que nombre otorgante a C, en la búsqueda de D no saldrá a la luz la notificación inscrita sobre la garantía real constituida por B en favor de A (respecto de la cuestión de si debería exigirse al acreedor garantizado que modificara su notificación inscrita para agregar al cesionario del otorgante inicial como nuevo otorgante, véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 9 a 12). Sin embargo, conforme a las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, la garantía real otorgada por B seguirá, en general, gravando el automóvil incluso hasta que pase a poder de D (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 79 y 81).

25. Para hacer frente al “problema A-B-C-D”, en algunos regímenes de las operaciones garantizadas se prevé un mecanismo suplementario de indexación y búsqueda basado en los bienes. En la práctica, ese enfoque es viable únicamente en el caso de los bienes muebles a los que se haya asignado un número de serie único y fiable o un identificador alfanumérico equivalente. Por ejemplo, la industria del automóvil utiliza un identificador alfanumérico único, llamado comúnmente número de identificación del vehículo automotor para individualizar cada vehículo automotor con arreglo a un sistema basado en normas establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). En los regímenes en que los interesados pueden recuperar notificaciones inscritas mediante un código alfanumérico único de ese tipo, el cesionario eventual que se halle en la situación de D estará a resguardo, porque cualquier consulta basada en ese código revelará todas las garantías reales constituidas por cualquier otro propietario anterior sobre el vehículo automotor de que se trate. Otros tipos de bienes respecto de los cuales se ha adoptado ese enfoque en algunos regímenes son los remolques, las casas rodantes, los fuselajes y motores de aeronaves, el material rodante ferroviario, las embarcaciones y sus motores.

26. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se examina, pero sin formular ninguna recomendación, la cuestión del uso del número de serie o el identificador alfanumérico equivalente de un bien como criterio de indexación y búsqueda (véase

la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 34 a 36). La desventaja de ese enfoque es que puede dificultar a las partes la constitución de una garantía real oponible sobre bienes futuros, porque el solicitante de la inscripción deberá modificar continuamente su notificación inscrita para agregar el número de serie u otro identificador de los bienes que adquiera el otorgante tras haberse inscrito la notificación inicial. Por consiguiente, en los Estados que han adoptado este enfoque, su aplicación se limita a los bienes que, además de haber recibido un identificador único, tienen alto valor de reventa y un mercado considerable en que efectuarla (por ejemplo, además de los vehículos automotores, los remolques, las casas rodantes, el fuselaje y los motores de aeronaves, el material rodante ferroviario, las embarcaciones y sus motores).

27. Además, conforme al régimen de las operaciones garantizadas de los Estados que han adoptado este enfoque, la inscripción registral del número de serie solo es obligatoria para lograr la oponibilidad y obtener prelación frente a los tipos de reclamantes concurrentes que puedan resultar más perjudicados por el “problema A-B-C-D” (en particular, los cesionarios de los bienes gravados). Frente a otras categorías de reclamantes concurrentes, por ejemplo los acreedores judiciales del otorgante o su administrador de la insolvencia, la inscripción registral de una notificación que no indique el número de serie en el espacio previsto para ello seguirá siendo válida frente a terceros, siempre que en ella se describa suficientemente el bien gravado. Además, consignar el número de serie no es obligatorio en absoluto cuando los bienes pertinentes formen parte de las existencias del otorgante. En este último caso, bastará con que la descripción de los bienes gravados que debe figurar en el espacio general destinado a ella se haga en términos genéricos, porque en el caso de las existencias no se presenta el “problema A-B-C-D”, debido a que los compradores que las adquieren del otorgante inicial en el curso ordinario de los negocios de ese otorgante las reciben en cualquier caso libres de toda garantía real (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 81, apartado a)).

7. Preservación de la integridad y seguridad del fichero del registro

28. Como ya se señaló (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párr. 38), para fomentar la confianza pública en la seguridad del fichero del registro, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que, aunque su gestión cotidiana pueda delegarse en una entidad privada, el Estado siga asumiendo la responsabilidad de supervisar el funcionamiento del registro y conserve la propiedad de su fichero, así como, en caso necesario, la de su infraestructura (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párr. 38). Otras medidas para garantizar la integridad y seguridad del fichero del registro son las siguientes: a) imponer al registro la obligación de solicitar la identificación del solicitante de la inscripción y dejar constancia de su identidad (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrs. 56 y 57); b) imponer al registro la obligación de enviar sin tardanza al solicitante de la inscripción copia de las notificaciones inscritas (véanse los párrs. 38 a 40 *infra*); c) exigir al solicitante de la inscripción que envíe sin tardanza copia de las notificaciones inscritas a la persona señalada en ellas como otorgante (véanse los párrs. 41 y 42 *infra*); y d) eliminar toda facultad discrecional del personal del registro para negar a los usuarios el acceso a sus servicios (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrs. 55 a 58).

29. Otras medidas para mantener la integridad del fichero del registro son las que se indican a continuación. En primer lugar, en el reglamento se debe dejar en claro que el personal del registro no podrá modificar ni retirar la información consignada en las notificaciones escritas, salvo disposición expresa en contrario de la ley y el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 17), y que esa información solo podrá modificarse mediante la inscripción de una notificación de modificación conforme a lo dispuesto en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 19). De cualquier modo, tal vez el Estado promulgante desee estudiar la posibilidad de autorizar al registro para corregir directamente la información consignada en una notificación inscrita si el solicitante de la inscripción la hubiera presentado en formato impreso y el registro no la hubiera consignado con exactitud ni íntegramente en el fichero. En caso de adoptarse este enfoque, se debería enviar sin tardanza al solicitante de la inscripción un aviso de esa corrección. En su defecto, el Estado promulgante podría exigir al registro que notificara de su error al solicitante de la inscripción, para que este pudiera presentar sin costo una notificación de modificación (en los párrafos 34 a 37, *supra* se examina la responsabilidad del Estado promulgante por toda pérdida o daño causado al solicitante de la inscripción o, por ejemplo, a otro acreedor garantizado que hubiera efectuado una inscripción antes de modificarse la notificación).

30. En segundo lugar, para proteger el fichero del registro del riesgo de daño o destrucción físicos, el Estado promulgante debería mantener copias de seguridad de su contenido (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 54, y recomendación 55, apartado f)).

31. En tercer lugar, debería reducirse al mínimo la posibilidad de corrupción del personal del registro, mediante las siguientes medidas: a) concebir el sistema de registro de manera que su personal no pueda modificar la fecha y hora de inscripción ni otra información consignada por el autor de una inscripción; b) establecer mecanismos de control financiero que supervisen estrictamente el acceso del personal a las sumas en efectivo abonadas en concepto de tasas y a la información financiera presentada por los clientes que utilicen otras formas de pago; y c) concebir el sistema de registro a fin de garantizar que en la copia archivada de las inscripciones registrales canceladas se conserven los datos consignados inicialmente.

32. En cuarto lugar, se debería dejar en claro al personal del registro y sus usuarios que, entre otras cosas, ese personal no está autorizado para prestar asesoramiento jurídico sobre los requisitos legales para dar validez a las inscripciones registrales y las consultas ni sobre los efectos jurídicos de unas y otras. De cualquier modo, el personal del registro debería estar en condiciones de impartir asesoramiento práctico sobre los procedimientos de inscripción y consulta (véanse los párrs. 34 a 36 *infra*).

33. Por último, como ya se explicó (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrs. 55 a 58 y 62 a 65), de ser posible, el registro debería concebirse de manera que los autores de inscripciones y quienes lo consultasen pudieran presentar directa y electrónicamente la información que desearan inscribir o utilizar en una consulta sin necesidad de que lo hiciera por ellos el personal del registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 54, apartado j)). Con arreglo a este enfoque, los usuarios serían los únicos responsables de cualquier error u omisión en el procedimiento de inscripción o consulta y les

correspondería también efectuar las correcciones o modificaciones necesarias (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 7, y el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párr. 61). De ese modo, se reducirían enormemente las posibilidades de corrupción o conducta impropia del personal del registro, porque sus funciones se limitarían en lo esencial a gestionar y facilitar el acceso electrónico de los usuarios, ocuparse de los trámites de pago de las tasas, supervisar el funcionamiento y mantenimiento del sistema del registro y reunir datos estadísticos.

8. Responsabilidad del registro

34. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que en el régimen de las operaciones garantizadas se prevea la forma de asignar responsabilidades legales por las pérdidas o los daños que causara un error en la gestión o el funcionamiento del sistema de inscripción y de consulta (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 76).

35. Como se señaló con anterioridad, legalmente los usuarios serán los únicos responsables por cualquier error u omisión en la información que inscriban o las solicitudes de consulta que presenten al registro, y les corresponderá también hacer las correcciones o modificaciones necesarias (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 7, y el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párr. 61). En consecuencia, cuando los usuarios presenten directamente por vía electrónica notificaciones y solicitudes de consulta, sin intervención del personal del registro, la eventual responsabilidad del Estado promulgante se limitará a los desperfectos del sistema, porque cualquier otro error sería atribuible al solicitante de la inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 56). Sin embargo, si se presentara una notificación o solicitud de consulta en formato impreso, el Estado promulgante tendría que determinar si le competía, y en qué medida, su responsabilidad en caso de que el personal del registro rehusara u omitiera incorporar correctamente en el fichero información que se deseara inscribir o dar cumplimiento apropiado a una solicitud de búsqueda cuando la notificación o la solicitud se presentara en formato impreso.

36. Aunque se debería dejar en claro que el personal del registro no está autorizado para prestar asesoramiento jurídico, el Estado promulgante deberá abordar también la cuestión de su posible responsabilidad y el alcance de ella en caso de que ese personal suministre información incorrecta o equívoca sobre los requisitos jurídicos para dar validez a una inscripción registral o una consulta, o sobre los efectos jurídicos de una y otra.

37. Cuando asumen una responsabilidad legal por las pérdidas o daños atribuibles a desperfectos del sistema, o a errores o conducta impropia del personal del registro, algunos Estados depositan parte de lo recaudado por el registro en concepto de tasas de inscripción y consulta en un fondo de indemnización destinado a cubrir posibles reclamaciones, mientras que en otros Estados, esas indemnizaciones se pagan con cargo a los ingresos generales.

9. Obligación del registro de enviar copia de una notificación inscrita a su autor

38. Como se señaló con anterioridad, la inscripción registral de una notificación adquiere validez en el momento en que la información en ella consignada se ingresa

en el fichero del registro para que puedan consultarla los interesados. Por la importancia de la fecha de validez de la inscripción para establecer la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda adoptar medidas para que el autor de una inscripción obtenga una copia de la misma apenas la información consignada en la notificación se haya inscrito en el fichero del registro y para que reciba información del registro sobre todo cambio que se introduzca en una notificación inicial (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 49 a 52, y recomendación 55, apartados d) y e)). Por consiguiente, el reglamento debería disponer que el registro remita prontamente una copia de la notificación inscrita (sea esta inicial, de modificación o de cancelación) a su autor, indicando la fecha y la hora en que pasó a ser oponible (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 18).

39. Si el registro tiene que enviar por correo ordinario una copia impresa de las notificaciones inscritas a su autor, este no puede dar por reconocida con rapidez la oponibilidad a terceros y la prelación de su garantía real. Así pues, de ser posible se debería concebir el registro de manera que generarse automáticamente una copia electrónica de toda notificación inscrita. Si el sistema permite que el autor de una inscripción la transmita electrónicamente, debería permitir también que se transmitiera automáticamente una copia electrónica de la notificación inscrita a su autor, mediante la interfaz electrónica común. Incluso si el solicitante de la inscripción presentara una notificación impresa, se debería concebir el sistema del registro de manera que permitiera transmitir electrónicamente copia de ella a su autor, por ejemplo en un documento adjunto a un mensaje de correo electrónico.

40. El solicitante de la inscripción querrá recibir copia de toda notificación de modificación o cancelación que haya presentado, a fin de adoptar sin dilación medidas adecuadas de resguardo en caso de que su inscripción no se hubiera autorizado o se hubiese efectuado incorrectamente. Hay algunas medidas eficaces que le protegerían del riesgo de modificaciones o cancelaciones fraudulentas efectuadas por un tercero (en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 28 a 37, se examina la validez de las notificaciones de modificación o cancelación no autorizadas por el acreedor garantizado).

10. Obligación del acreedor garantizado de enviar al otorgante una copia de la notificación inscrita

41. Como se señaló anteriormente (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párr. 60), el acreedor garantizado debe obtener la autorización por escrito del otorgante, en el acuerdo de garantía o en un acuerdo independiente, para efectuar una inscripción. Para que la persona que figure como otorgante en una notificación escrita pueda verificar que esa inscripción registral se autorizó efectivamente y que la información consignada en ella corresponde al alcance de la autorización, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda disponer que el acreedor garantizado envíe al otorgante una copia de la notificación inscrita (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 55, apartado c)). Esa recomendación debería reflejarse en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 18, apartado b)).

42. Imponer al acreedor garantizado y no al registro la obligación de enviar al otorgante una copia de la notificación tiene por objeto evitar que el registro asuma una nueva carga, que podría reducir su eficiencia. Dándose por entendido que en la

mayoría de los casos la inscripción se hace de buena fe y será autorizada, el hecho de que el acreedor garantizado no cumpla su obligación no es una condición previa de la validez de la inscripción, sino que dará lugar únicamente a sanciones menores y la exigencia de indemnizar al otorgante por todo daño real que haya causado ese incumplimiento (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, capítulo IV, párr. 51, y recomendación 55 apartado c)), y párrs. 41 y 42 *supra*.

11. Modificación de la información consignada en el fichero del registro accesible al público

43. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda facultar al acreedor garantizado para modificar en cualquier momento, mediante una notificación de modificación, la información consignada en una notificación inscrita, (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 110 a 116, y recomendación 73). En la *Guía* se recomienda también que, en determinadas circunstancias, se permita al otorgante solicitar una modificación por vía judicial o administrativa. (Véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* cap. IV, párrs. 107 y 108, y recomendación 72). Por la importancia de esas recomendaciones, el reglamento podría reflejarlas y, además, señalar la información que debería contener toda notificación de modificación (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 19 y los párrs. 50 a 53 *infra*).

12. Retirada y archivo de la información del fichero del registro accesible al público

44. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que la información contenida en una notificación inscrita se retire del fichero accesible al público en un breve plazo tras expirar la validez de esa notificación o una vez que se inscriba una notificación de cancelación; acto seguido, esa información deberá archivarse para que pueda recuperarse en caso necesario (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 109, y recomendación 74). Si las notificaciones canceladas o vencidas siguieran siendo consultables públicamente, podría crearse incertidumbre jurídica para los terceros que consultaran el registro, y resultaría más difícil para el otorgante constituir una nueva garantía real o negociar con los bienes descritos en la notificación. De cualquier manera, el archivo se debería realizar de un modo que permitiera recuperar las notificaciones, porque podría resultar necesario volver a consultar en el futuro las notificaciones vencidas o canceladas, por ejemplo, para determinar la fecha de su inscripción o la magnitud y el alcance de los bienes gravados en toda controversia posterior sobre prelación entre el solicitante de la inscripción y un demandante concurrente. En el reglamento deberían figurar reglas por las que se aplicaran esas recomendaciones (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendaciones 20 y 21).

45. En el reglamento se debería indicar también un período mínimo durante el cual habrían de conservarse las notificaciones archivadas (por ejemplo, 20 años) (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 21). La duración de ese período de archivo podrá depender de la del plazo de prescripción, con arreglo a la ley del Estado promulgante relativa a la presentación de reclamaciones. Por ejemplo, con respecto a las garantías reales, si la legislación dispone que no pueden entablarse acciones judiciales una vez transcurridos más de 15 años desde la fecha de extinción de la garantía real o de rescisión del acuerdo de garantía, en el reglamento del registro podría preverse un período de archivo similar. Al decidir sobre el período

apropiado, el Estado promulgante debería examinar también si la ley permite prorrogar el plazo de prescripción y si, en consecuencia, el registro debería conservar la información en sus archivos por un período equivalente al de toda prórroga permitida.

13. Idioma de las notificaciones y las solicitudes de consulta

46. Aunque en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no se formula ninguna recomendación concreta sobre el idioma en que hayan de presentarse al registro la información que se desee inscribir y las solicitudes de consulta, el comentario alude a la necesidad de que el Estado promulgante se ocupe de esa cuestión en el reglamento del registro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 44 a 46). Por consiguiente, ese asunto debería abordarse en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 22).

47. Sea cual fuere el idioma que se utilice en el escrito constitutivo de la garantía, el reglamento exigiría normalmente que en la información que se deseara inscribir y las solicitudes de consulta se utilizara el idioma o los idiomas oficiales del Estado bajo cuya jurisdicción funcionara el registro. Aunque el Estado promulgante podría autorizar también la utilización de otros idiomas, ello reduciría la eficacia y transparencia del fichero del registro, a menos que cupiera prever que los comprendiese la mayoría de quienes efectuaran consultas en el Estado promulgante.

48. La única excepción a esa regla sería el caso en que el nombre legal del otorgante, por ejemplo una empresa constituida con arreglo a la legislación de otro país, se escribiera en un idioma distinto del utilizado por el registro. Para hacer frente a las situaciones en que el idioma en que se escribiera el nombre utilizara caracteres distintos de los empleados en el idioma o los idiomas del registro, sería necesario que en el reglamento se impartiera orientación respecto de la forma de ajustar o transliterar esos caracteres para adaptarlos al idioma del registro. Las mismas consideraciones se aplican al nombre del acreedor garantizado.

49. Si el otorgante fuese una persona jurídica y el régimen conforme al cual se hubiera constituido permitiera utilizar otras versiones lingüísticas de su nombre, el reglamento debería disponer expresamente que todas esas versiones habrían de consignarse por separado como identificadores del otorgante, a reserva de lo previsto en el mismo reglamento sobre la forma en que se deben ajustar o transcribir los nombres escritos en caracteres extranjeros a fin de adaptarlos al idioma o los idiomas del registro. Ello es necesario para proteger a los terceros que hagan o hayan hecho negocios con el mismo otorgante cuando se haya identificado a este con cualquier otra de las versiones de su nombre y que, por tanto, podrían consultar el registro utilizándola.

B. Recomendaciones 11 a 22

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las recomendaciones 11 a 22, tal como se reproducen en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.5. El Grupo de Trabajo quizá desee observar también que, por razones de economía, las recomendaciones no se han incluido en el presente documento en esta etapa pero se incluirán en el texto definitivo.]

IV. Inscripción de notificaciones iniciales

A. Observaciones generales

1. Introducción

50. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 65 a 97, y la recomendación 57) que, para que el registro admita la inscripción de una notificación inicial se debe presentar única y exclusivamente la siguiente información: a) el dato de identificación, o identificador, del otorgante, y su dirección; b) el identificador y la dirección del acreedor garantizado o su representante; c) una descripción del bien gravado; y d) el plazo de vigencia de la inscripción registral, en caso de que el Estado promulgante haya adoptado en su régimen de las operaciones garantizadas la variante de permitir que el solicitante de la inscripción elija el plazo de vigencia de la notificación (véanse los párrs. 7 a 15 *supra*); y e) el importe monetario máximo por el que el acreedor garantizado podrá ejecutar la garantía real, si el Estado promulgante opta por exigir esa información conforme a su régimen de las operaciones garantizadas (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3 párrs. 15 a 19). En el reglamento se debería reflejar y complementar esa recomendación (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 23). En los siguientes párrafos se examina cada uno de los aspectos del contenido necesario de toda notificación.

51. Como se señaló con anterioridad, (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párr. 57), el solicitante de la inscripción deberá consignar la información requerida en el espacio previsto en el formulario de notificación prescrito para consignarla (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendaciones 7 y 23). Si el solicitante de la inscripción consignara, por ejemplo, el identificador del otorgante en el espacio para el acreedor garantizado, ello no sería motivo para que el registro rechazara la notificación. Sin embargo, la inscripción de esta notificación puede resultar inválida, lo que significaría que la garantía real a que se refiere no sería oponible a terceros.

2. Información sobre el otorgante

a) Observaciones generales

52. Como ya se explicó (véanse los párrafos 21 a 23 *supra*), en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que las notificaciones inscritas se indexen y organicen de manera que puedan encontrarse utilizando como criterio de consulta el identificador del otorgante. En consonancia con las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véanse las recomendaciones 58 a 60), en el reglamento se debería impartir orientación detallada sobre lo que constituye el identificador correcto del otorgante, para que el autor de una inscripción tuviera la certeza de que esta sería válida y los interesados pudieran fiarse del resultado de su búsqueda (véase el proyecto de guía sobre el registro, párrs. 54 a 68 y recomendaciones 24 a 26, *infra*). En el reglamento se debería impartir también orientación acerca de las consecuencias de presentar información incorrecta o insuficiente sobre el identificador del otorgante (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3, párrs. 20 a 23, y la recomendación 29, apartado a), *infra*).

53. No es inusual que una persona constituya una garantía real sobre sus bienes para garantizar una obligación adeudada por un tercero deudor (incluidos los terceros garantes de la obligación contraída por el otorgante). Como la función de la inscripción es revelar la posible existencia de una garantía real sobre los bienes descritos en la notificación, los autores de la inscripción deberían comprender que la información requerida sobre el otorgante es el identificador y la dirección del otorgante que sea el propietario de los bienes gravados o tenga derechos sobre ellos, y no la relativa al tercero deudor de la obligación garantizada (o a un mero garante de la obligación de ese deudor). Si hay más de un otorgante, en el reglamento se debería señalar que los identificadores y direcciones de cada cual han de consignarse por separado en los espacios previstos para ello en la notificación. Esto es necesario para asegurar que toda consulta del registro en que se utilice el identificador de uno de los otorgantes permita localizar la notificación inscrita (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3, párrs. 20 a 23). Para facilitar la inscripción, se debería prever que en el formulario de notificación prescrito pudieran consignarse simultáneamente los identificadores y las direcciones de varios otorgantes (en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.6 figuran ejemplos de formularios de inscripción). Aunque el solicitante de la inscripción podría lograr el mismo resultado si inscribiera una notificación por otorgante, ello sería más engorroso, porque tendría que volver a consignar en cada una de ellas toda la información necesaria.

b) Identificador del otorgante correspondiente a personas físicas o a personas jurídicas

54. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se formulan recomendaciones distintas para determinar el identificador del otorgante, según se trate de una persona física o jurídica o de otra entidad (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 59 y 60). Por consiguiente, las notificaciones inscritas deberán indexarse u organizarse de otro modo en el fichero del registro, conforme a distintos criterios, según la categoría del otorgante.

55. Ese enfoque repercute en la inscripción y la búsqueda. Para garantizar que la información consignada en una notificación se inscriba correctamente en el fichero del registro a fin de que pueda consultarla el interesado, en el reglamento se debería indicar con claridad que el solicitante de la inscripción deberá consignar el identificador y la dirección del otorgante en los espacios previstos para la información correspondiente a esa categoría de otorgante. Para ello, en el formulario de notificación prescrito, y en el de la solicitud de consulta, deberían preverse espacios distintos para consignar el identificador y la dirección de los otorgantes de cada categoría (véanse los ejemplos de formularios de inscripción que figuran en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.6).

c) Identificador del otorgante como persona física

56. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que, si el otorgante es una persona física, el dato de identificación, o identificador necesario, para dar validez a la inscripción registral sea el nombre de ese otorgante que figure en un documento oficial prescrito para dicho fin (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 59). A fin de aplicar esa recomendación, en el reglamento se deberían indicar los tipos de documentos oficiales en que a

juicio del Estado promulgante se establezca autorizadamente el nombre del otorgante, así como la jerarquía de esos documentos oficiales. En el cuadro que figura a continuación se ilustra el tipo de enfoque que podría adoptarse, aunque el Estado promulgante debería determinar los tipos de documentos oficiales que considerase más apropiados, según la nomenclatura que utilizara (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 24).

Condición del otorgante	Identificador del otorgante
Nacido en el Estado promulgante e inscrito en ese Estado	Nombre que figura en la partida de nacimiento o el documento oficial equivalente
Nacido en el Estado promulgante pero sin haberse inscrito en él su nacimiento	1) Nombre que figura en el pasaporte actualmente válido 2) A falta de pasaporte actualmente válido, nombre que figura en el documento oficial equivalente, como la tarjeta de identidad o la licencia de conducir
No nacido en el Estado promulgante pero naturalizado en ese Estado	Nombre que figura en el certificado de nacionalidad
No nacido en el Estado promulgante ni nacionalizado como ciudadano suyo	1) Nombre que figura en el pasaporte actualmente válido expedido por el Estado del que el otorgante sea ciudadano 2) A falta de un pasaporte extranjero actualmente válido, nombre que figura en la partida de nacimiento o en el documento oficial equivalente que se haya emitido en el lugar de nacimiento del otorgante
Ninguno de los anteriores	Nombre que consta en dos documentos oficiales cualesquiera emitidos por el Estado promulgante, si esos nombres son idénticos (por ejemplo, en la tarjeta de la seguridad social, del seguro médico o la tarjeta fiscal)

57. En el reglamento se deberían señalar los componentes del nombre del otorgante que habrían de indicarse en la notificación prescrita (por ejemplo, el apellido, seguido del primer nombre, seguido del segundo nombre) y prever en ella distintos espacios para consignar cada uno de ellos. Al decidir qué componentes se requerirían, el Estado promulgante debería tener en cuenta las convenciones locales relativas a los nombres, así como el grado en que se detallaran en los documentos oficiales expedidos internamente los distintos componentes del nombre. Además, se debería impartir orientación para abordar casos excepcionales. Por ejemplo, si el nombre del otorgante consistiera en una sola palabra, en el reglamento se debería disponer que esa palabra se consignara en el espacio reservado para el apellido, y el sistema de registro debería concebirse de manera que no rechazara las notificaciones en que se dejaran en blanco los espacios previstos para los nombres (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 24, apartado b)).

58. Tal vez el Estado promulgante desee examinar si durante el trámite de inscripción el registro debería prever el cotejo electrónico de los nombres consignados en las notificaciones inscritas con los que figurasen en otras bases de datos que mantuviera ese Estado. A ese respecto, se deberían tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que el registro no debería prestar ese servicio a menos que tuviera la certeza de que la base de datos a la que está conectado es completa y exacta y se halla actualizada. De lo contrario, prestaría un servicio contraproducente y podría exponerse a responsabilidades. La segunda cuestión es el efecto jurídico de ofrecer servicios de cotejo. Una opción sería que se previera en el reglamento que todo documento encontrado mediante ese cotejo bastara jurídicamente para identificar al otorgante. Conforme a ese enfoque, el cotejo electrónico trasladaría la responsabilidad legal de identificar correctamente al otorgante del solicitante de la inscripción al registro, exponiéndolo con ello a posibles reclamaciones. La otra opción sería disponer que ese servicio no tuviera ningún efecto jurídico y que siguiera correspondiendo al solicitante de la inscripción que recurriese al cotejo electrónico verificar la exactitud del identificador del otorgante que figurara en la base de datos externa. Ese último enfoque se ajusta más a las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

59. En algunos Estados, muchas personas pueden tener el mismo nombre, lo que significa que una búsqueda puede conducir a muchos otorgantes que se llamen de idéntica manera. Para ajustarse a esa situación, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que, cuando sea necesario se consigne en la notificación otra información además del nombre del otorgante (como su fecha de nacimiento, el número de su tarjeta de identidad u otro número oficial emitido por el Estado promulgante) para identificar inequívocamente a ese otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 59). Sin embargo, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no se recomienda utilizar como criterio de búsqueda esa información suplementaria. Los Estados que deseen aplicar esa recomendación deberían señalar en el reglamento el tipo de información suplementaria a que pudiera recurrirse, y si sería obligatorio consignarla para que la inscripción registral fuese aceptada por el registro, o si su inclusión quedaría a criterio del solicitante de la inscripción (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 23, apartado a), inciso i)).

60. Que el Estado promulgante imponga o no la obligación de incluir en la notificación el número del documento de identidad u otro documento oficial expedido por ese Estado, a modo de información suplementaria, depende de tres consideraciones importantes. En primer lugar, que el sistema de registro con arreglo al cual se expidan los números de los documentos de identidad sea de alcance universal y lo bastante fiable para garantizar que se asigne a toda persona física un número permanente y único. En segundo lugar que la política de orden público del Estado promulgante permita la divulgación pública del número del documento de identidad u otro documento que asigne a sus ciudadanos o residentes. En tercer lugar, que exista un registro documental fiable u otra fuente cuya consulta permita a los terceros verificar objetivamente si un número determinado corresponde al otorgante de que se trate. Si se cumplen estas tres condiciones, la utilización del número del documento de identidad u otro documento oficial expedido por el Estado sería la forma ideal de identificar inequívocamente al otorgante. Sin embargo, como ya se señaló, el enfoque recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* es que la información suplementaria, ya se trate del número de la

tarjeta de identidad o el de otro documento, podrá requerirse únicamente cuando sea necesaria para identificar inequívocamente al otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 59), y solo como requisito que complemente el de ingresar el nombre del otorgante (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 23, apartado a), inciso i)), al tiempo que, de cualquier modo no deberá utilizarse como criterio de consulta (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 34).

61. Habida cuenta de las recomendaciones de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* relativas al conflicto de leyes (por ejemplo, la recomendación 203, conforme a la cual la ley aplicable a la constitución de toda garantía real sobre bienes corporales, su oponibilidad a terceros y su grado de prelación debería ser la ley del Estado en que esté situado el bien), la legislación del Estado promulgante (incluido el reglamento de su registro) podría aplicarse a toda garantía real constituida por un otorgante extranjero. De ese modo, cuando el Estado promulgante requiriese que se consignara el número del documento de identidad u otro documento oficial expedido por el Estado para identificar inequívocamente al otorgante, se deberían prever en el reglamento los casos en que el otorgante no fuera ciudadano del Estado promulgante ni residiera en él, y aquellos en que, por cualquier otra razón, no se le hubiera asignado un número de identificación. Por ejemplo, el Estado promulgante podría disponer en su reglamento que bastara con el número de pasaporte extranjero del otorgante o el número de cualquier otro documento oficial extranjero.

d) Identificador del otorgante como persona jurídica

62. Si el otorgante es una persona jurídica, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que se considere identificador correcto a efectos de la validez de la inscripción el nombre que aparezca en la escritura constitutiva de dicha persona jurídica (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 60). En el reglamento se debería recoger y complementar esa norma. En particular, en él se debería dejar en claro que la escritura constitutiva pertinente podrá ser cualquier tipo de instrumento (ya se trate de un contrato privado, de una ley o de un decreto) que sea el fundamento legal de la condición de persona jurídica del otorgante con arreglo a la ley que haya regido su constitución (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 25).

63. Casi todos los Estados llevan un registro de las sociedades mercantiles para archivar los datos, incluido el nombre, de toda persona jurídica constituida con arreglo a su legislación interna. En algunos Estados, al inscribirse una persona jurídica en el registro, se le asigna un número único y fiable. Si preocupa al Estado promulgante la posibilidad de que varias personas jurídicas tengan el mismo nombre, podría disponerse en el reglamento que se incluyera ese número en la notificación, a modo de información suplementaria para identificar inequívocamente al otorgante (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 25, opción B). En los Estados que requiriesen esa información suplementaria, el reglamento debería impartir orientación para resolver los casos en que el otorgante fuese una persona jurídica constituida conforme al derecho de un Estado extranjero, porque en los registros de las sociedades mercantiles de otros Estados tal vez no exista un sistema de numeración equivalente.

64. Cuando el otorgante es una persona jurídica, su nombre incluye normalmente abreviaturas genéricas (por ejemplo, “S.A.”, “S.L.”, “S.R.L.”, etc.) o palabras (como “limitada”, “sociedad anónima”, etc.) indicativas del tipo de sociedad o persona jurídica de que se trata. En el reglamento se debería dejar en claro que esas abreviaturas o palabras son un componente optativo del identificador del otorgante, en el sentido de que incluirlas o no en la búsqueda, o utilizar en esta una versión errónea de ellas, permitiría de todos modos localizar la inscripción pertinente. Al reconocer ese carácter optativo se protegería a los autores de inscripciones que no consignaran la abreviatura genérica correcta o sencillamente la omitieran. Sin embargo, ello podría reducir la transparencia para los terceros autores de consultas, porque la búsqueda conduciría a todos los otorgantes que fueran personas jurídicas y compartieran ese nombre determinado, con independencia de su categoría.

65. Según sea el derecho aplicable a la constitución del otorgante como persona jurídica, la escritura u otro instrumento constitutivo puede contener variantes contradictorias del nombre (por ejemplo, la entidad podría figurar diversamente en ella como “la ABC S.A” o “ABC S.A” o “ABC”). Lo ideal sería que en el reglamento se impartiera orientación sobre la parte de la escritura constitutiva que hubiese de considerarse fuente fidedigna del nombre del otorgante a efectos de la inscripción registral.

e) Casos especiales

66. En el reglamento deberían figurar también otras directrices sobre el identificador del otorgante que se requiriese cuando este no correspondiera plenamente a la categoría de persona física ni a la de persona jurídica (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 26). En ese aspecto, la cuestión no es si el otorgante tiene capacidad jurídica para constituir una garantía real, sino más bien la forma en que ha de consignarse su identificador en la notificación. En el cuadro que figura a continuación se presentan las distintas situaciones que deben considerarse, con ejemplos de posibles identificadores. Los Estados promulgantes deberán examinar la conveniencia de adaptar estos ejemplos a su contexto y la forma de hacerlo.

Condición del otorgante	Identificador del otorgante
Masa de la insolvencia, por conducto de un representante de la insolvencia	Nombre de la persona insolvente, consignado de conformidad con las normas aplicables a los otorgantes que son personas físicas o jurídicas, según el caso, con indicación en un espacio aparte previsto para tal efecto de que el otorgante es insolvente
Consorcio o empresa conjunta	Nombre del consorcio o de la empresa conjunta tal como figura en la escritura constitutiva, consignado en el espacio previsto para anotar el identificador de la persona jurídica

Condición del otorgante	Identificador del otorgante
Fideicomisario o representante encargado de la administración de la masa	Nombre del fideicomisario o del representante encargado de la administración de la masa, consignado de conformidad con las normas aplicables a los otorgantes que son personas físicas o jurídicas, según el caso, con la indicación, en un espacio aparte, de que el otorgante actúa como fideicomisario o representante encargado de la administración de la masa
Otra entidad	Nombre de la entidad, como figura en la escritura constitutiva y consignado de conformidad con las normas aplicables a los otorgantes que son personas jurídicas

67. Si se trata de un negocio de propiedad unipersonal, aunque se administre bajo un nombre y con estilo comercial distintos del de su propietario, el reglamento debería disponer que el identificador del otorgante fuera el nombre del propietario consignado con arreglo a las normas aplicables a los otorgantes que son personas físicas. El nombre de la propiedad unipersonal no es un dato fiable, pues el propietario puede cambiarlo a voluntad. Aunque el solicitante de la inscripción podrá consignar en ella el nombre de la propiedad unipersonal como uno de los otorgantes, el identificador requerido es el nombre del propietario.

68. En el cuadro que figura más arriba, si el otorgante lo es en relación con la masa de la insolvencia por conducto de un representante de la insolvencia, el solicitante de la inscripción, además de indicar el nombre de la persona insolvente en el espacio correspondiente al otorgante, deberá indicar en un espacio distinto que el otorgante es insolvente. De manera análoga, si el otorgante es fideicomisario o representante encargado de la administración de la masa, el solicitante de la inscripción, además de indicar el nombre de ese fideicomisario o representante en el espacio correspondiente al otorgante, deberá indicar en un espacio distinto que el otorgante actúa en nombre de un fideicomiso o es el representante encargado de la administración de la masa. Por consiguiente, el formulario de notificación prescrito deberá contener un espacio previsto expresamente para consignar esa información suplementaria.

f) Dirección del otorgante

69. Con arreglo a la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, la dirección del otorgante forma parte del contenido obligatorio de la notificación (véase la *Guía, sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, apartado a)). Ello es importante para que pueda enviarse al otorgante una copia de las notificaciones inscritas (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 55, apartados c) y d)). En consecuencia, el solicitante de la inscripción deberá consignar la dirección actual conocida del otorgante. Como, esa dirección no forma parte del identificador del otorgante en el sentido de que constituya un criterio de búsqueda, en el formulario prescrito de la notificación se debería prever un espacio para consignarla, distinto del que se destine al identificador del otorgante. En el reglamento deberían recogerse y, en caso necesario complementarse, estas recomendaciones.

70. Algunos Estados no exigen consignar la dirección del otorgante cuando por razones de seguridad no convenga revelar la dirección de una persona en un documento de acceso público. Si se reconoce esa excepción, podría señalarse en el reglamento la necesidad de consignar un apartado postal o una dirección postal análoga que no corresponda a una residencia.

71. Consignar en la notificación la dirección del otorgante sirve también para identificar inequívocamente a este en los Estados en que muchas personas puedan tener el mismo nombre y en que, por ello, la búsqueda revele la existencia de varias garantías reales constituidas por distintos otorgantes de igual nombre (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 59). A este nivel, la dirección del otorgante es menos importante en los sistemas en que se exija que el solicitante de la inscripción incluya información suplementaria para identificar inequívocamente al otorgante, como su fecha de nacimiento o el número de su documento de identidad expedido por el Estado (véanse los párrafos 59 a 61, *supra*).

(A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23º período de sesiones**ADICIÓN****Índice**

	<i>Párrafos</i>
IV. Inscripción de notificaciones iniciales	1-35
A. Observaciones generales.	1-35
2. Información sobre el acreedor garantizado	1-4
3. Descripción de los bienes gravados	5-13
4. Plazo de validez de la notificación inscrita	14
5. Importe máximo por el que se puede ejecutar la garantía real	15-19
6. Efecto de los errores u omisiones sobre la validez de la inscripción registral de una notificación.	20-35
B. Recomendaciones 23 a 29.	

IV. Inscripción de notificaciones iniciales (*continuación*)**A. Observaciones generales (*continuación*)****2. Información sobre el acreedor garantizado**

1. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda incluir en la notificación inscrita en el registro el identificador del acreedor garantizado o el de su representante, junto con su dirección (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, apartado a)). El reglamento debería reiterar esta recomendación y, cuando proceda, complementarla (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 27).

2. El reglamento debería disponer que las mismas normas sobre el identificador que se aplican al otorgante se apliquen también al acreedor garantizado o a su representante. Cabe señalar a este respecto que el agente o fideicomisario de un consorcio de prestamistas será el representante del acreedor garantizado si la garantía real se otorga al consorcio de prestamistas, pero será un “acreedor garantizado” si la garantía real se “otorga” al mandatario (aunque sea con carácter nominal). Un tercero proveedor de servicios, que podría presentar una notificación en nombre del acreedor garantizado, no será ni el acreedor garantizado ni su representante en el sentido de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, a menos que el nombre del proveedor de servicios figure en el espacio previsto en la notificación inscrita para el acreedor garantizado.

3. El identificador del acreedor garantizado o su representante no constituye un criterio de indexación ni de búsqueda (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 21 a 23, y A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 42 a 45). Por consiguiente, las consecuencias de una declaración incorrecta o insuficiente relativa al identificador del acreedor garantizado difieren de las de una declaración incorrecta o insuficiente relativa al identificador del otorgante (véanse los párrafos 20 a 24 *infra*); y, aun cuando el reglamento exija que se agreguen datos de identificación adicionales para identificar inequívocamente al otorgante (por ejemplo, la fecha de nacimiento o un número de identificación personal), no es necesario hacer extensivo este requisito al acreedor garantizado.

4. El identificador del acreedor garantizado que debe consignarse en la notificación podrá ser el del propio acreedor garantizado o el de su representante. Este enfoque tiene por objeto facilitar, por ejemplo, los préstamos sindicados, ya que solo es preciso especificar en una notificación el identificador del fideicomisario o el agente del consorcio de prestamistas. También tiene por objeto proteger la privacidad del acreedor garantizado. Los derechos del otorgante no se ven afectados, dado que este tiene una relación directa con el acreedor garantizado y conoce su identidad. Los derechos de terceros tampoco se verán afectados siempre que el representante identificado en la notificación como acreedor garantizado esté autorizado a actuar en nombre del verdadero acreedor garantizado en toda comunicación o controversia relacionada con la garantía real objeto de la notificación.

3. Descripción de los bienes gravados

a) Observaciones generales

5. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que, para que una notificación surta efecto deberá contener una descripción de los bienes gravados a los que se refiera la garantía real relacionada con la inscripción registral (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, apartado b)). Este enfoque permite a los terceros que realizan operaciones con los bienes de una persona (como posibles acreedores garantizados, compradores, acreedores judiciales y el representante de esa persona en un procedimiento de insolvencia) determinar qué bienes de esa persona pueden estar gravados por una garantía real y cuáles no. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* también recomienda que una descripción de los bienes gravados se considere suficiente a efectos de validez del acuerdo de garantía y la inscripción registral, siempre que permita razonablemente identificar los bienes gravados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 14, apartado d), y 63). Según el carácter del bien gravado, la descripción podrá ser específica o genérica. Por ejemplo, si el bien gravado es uno de los muchos cuadros que posee el otorgante, la descripción que figure en la notificación podrá especificar el título del cuadro y el nombre del pintor a fin de identificar suficientemente el cuadro que habrá de ser objeto de gravamen. En cambio, si los bienes gravados pertenecen a categorías genéricas de bienes, como todas las existencias de una galería de arte, bastaría con describirlos genéricamente, por ejemplo, como “todos los cuadros del otorgante”, “todas las obras de arte del otorgante” o “todas las existencias del otorgante”.

6. El reglamento debería reiterar esta recomendación y, cuando proceda, complementarla (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 28). En particular, el reglamento debería indicar expresamente que la descripción de los

bienes gravados que figure en una notificación podrá ser específica o genérica siempre que permita identificarlos razonablemente. Asimismo, el reglamento debería precisar que se entenderá que una descripción referida a todos los bienes de una categoría genérica o a todos los bienes de un otorgante incluye los bienes futuros pertenecientes a la categoría especificada sobre los que el otorgante adquiera derechos mientras la notificación tenga validez.

7. Si el formulario de notificación prescrito limita el número de caracteres que pueden anotarse en el espacio destinado a la descripción de los bienes gravados y se necesita espacio adicional (por ejemplo, para identificar los bienes gravados más pormenorizadamente), el formulario del registro debería diseñarse de modo que permita incluir información adicional en un anexo o cuadro adjunto a la notificación. Por lo general, esto solo es necesario cuando la notificación se hace en un formulario impreso, puesto que un formulario electrónico no plantea problemas de espacio.

b) Descripción de bienes “con número de serie”

8. Como se ha mencionado (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 24 a 27), los regímenes de las operaciones garantizadas de algunos Estados prevén un mecanismo de indexación y consulta suplementario basado en los bienes respecto de determinadas categorías de bienes de alto valor para los que existe un considerable mercado de reventa. En los ordenamientos jurídicos que adoptan este enfoque se debe especificar el número de serie en el espacio previsto para ello, lo cual es necesario a efectos de oponibilidad a terceros y prelación con respecto a determinadas clases de terceros que adquieran derechos sobre el bien en cuestión.

9. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se examina este enfoque, pero no se recomienda (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 34 a 36). No obstante, incluso en los sistemas que no adoptan este enfoque, si los bienes gravados tienen un número de serie, el autor de una inscripción tal vez desee incluirlo en la descripción que consigne en la notificación, ya que se trata de un método económico para identificar suficientemente el bien gravado de modo que pueda identificarse razonablemente (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 63 y 14, apartado d)). A tal efecto, el formulario de notificación debería diseñarse de tal modo que permita al solicitante de la inscripción especificar en él el número de serie, si así lo desea. No obstante, se debería aclarar que el número de serie es un componente opcional y no obligatorio de una descripción eficaz, siempre que la descripción que figure en la notificación permita identificar suficientemente el bien de que se trate. Asimismo, el número de serie no debería constituir un criterio de búsqueda legalmente válido. Por consiguiente, aun cuando el registro permita utilizar el número de serie como criterio para crear índices y efectuar consultas, las búsquedas por número de serie deberían ser opcionales y, por consiguiente, el hecho de que no arrojen ningún resultado no debería ser determinante.

c) Descripción del producto

10. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que una garantía real se haga extensiva automáticamente a todo bien identificable que dimane de los bienes gravados, salvo acuerdo en contrario de las partes en el acuerdo de garantía (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, Introducción, secc. B,

“producto”, y recomendación 19). En los casos en que la garantía real sobre los bienes gravados originales se haya hecho oponible a terceros mediante inscripción registral, se plantea la cuestión de si el acreedor garantizado necesita modificar la descripción de los bienes gravados contenida en la notificación inicial a fin de incluir una descripción del producto y asegurarse de que su garantía real sobre el producto también sea oponible a terceros.

11. Si el producto consiste en efectivo u otro producto equiparable (por ejemplo, dinero o títulos negociables), la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la oponibilidad de una garantía real sobre los bienes gravados originales inscrita anteriormente sea automáticamente extensiva al producto. Lo mismo vale cuando el tipo de producto ya está comprendido en la descripción de los bienes gravados originales que figura en la notificación inscrita (por ejemplo, la descripción abarca “todos los bienes corporales” y el otorgante intercambia un componente de un bien de equipo por otro; véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 39).

12. No obstante, cuando el producto no consiste en efectivo ni en otro producto equiparable y no está comprendido en la descripción de los bienes gravados que figura en la notificación inscrita, el acreedor garantizado deberá modificar su inscripción registral a fin de añadir una descripción del producto en un breve plazo después de que este se origine, a fin de preservar la oponibilidad a terceros y la prelación de su garantía real sobre el producto desde la fecha de la inscripción inicial (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 40). Esa modificación es necesaria porque, de lo contrario, un tercero no podría identificar qué categorías de bienes en posesión del otorgante constituirían el producto pertinente.

d) Descripción de los bienes gravados incorporados a un bien inmueble

13. Conforme a lo ya tratado (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párrs. 21 a 23), como cualquier otro tipo de bien gravado, un bien corporal que haya sido o vaya a ser incorporado a un bien inmueble deberá describirse en la notificación inscrita en el registro general de garantías reales de manera que permita razonablemente identificarlo (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 14, apartado d), y 63). Si bien una descripción genérica del bien puede bastar para tal fin, el solicitante de la inscripción podría necesitar también hacer una inscripción en el registro de la propiedad inmobiliaria a fin de asegurarse de que su garantía real sea oponible a terceros que adquieran una garantía sobre el bien inmueble pertinente y la inscriban. En los registros de la propiedad inmobiliaria, las inscripciones suelen indexarse u organizarse por remisión al bien inmueble concreto, en lugar de al identificador del otorgante. Así pues, para que la notificación también se pueda inscribir en el registro de la propiedad inmobiliaria, la descripción del bien contenida en la notificación deberá describir el bien inmueble concreto. Además, las normas que regulan la inscripción en el registro de la propiedad inmobiliaria tal vez tengan que ser revisadas para permitir la inscripción registral de notificaciones y la descripción genérica de bienes gravados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párr. 104). Por otra parte, si el otorgante de la garantía real sobre el bien no es el propietario del bien inmueble conexo, la notificación podría tener que identificar también al propietario del bien si dicha información fuera necesaria para indexar la notificación en el registro de la propiedad inmobiliaria.

4. Plazo de validez de la notificación inscrita

14. Como ya se vio (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 7 a 15), el régimen de las operaciones garantizadas de un Estado promulgante puede fijar por ley un plazo de vigencia uniforme de todas las inscripciones registrales (opción A) o puede ofrecer a los autores de inscripciones la opción de que ellos mismos determinen el período de vigencia (opción B). En los Estados que eligen la opción B, el reglamento debería especificar que la inclusión del plazo de vigencia de una inscripción registral en el espacio previsto para ello es un componente obligatorio de la información que debe figurar en una notificación inscrita (véanse la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 69, y el proyecto de guía sobre el registro, recomendaciones 13 y 23, apartado a), inciso iv)). Si el Estado promulgante impone un límite máximo al derecho del solicitante de la inscripción a determinar el plazo de vigencia de la notificación (opción C), el registro debería diseñarse de tal manera que el autor de una inscripción no pudiera especificar un período que exceda el límite máximo.

5. Importe máximo por el que se puede ejecutar la garantía real

15. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce que algunos Estados pueden exigir que en el acuerdo de garantía y en la notificación inscrita se especifique el importe monetario máximo por el que se puede ejecutar la garantía real (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 92 a 97, y las recomendaciones 14, apartado d), y 57, apartado d)). No obstante, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no da lugar a que este requisito se utilice como pretexto para imponer una tasa a las operaciones garantizadas. Las tasas de inscripción, si las hubiere, no deberían ser superiores a lo requerido para cubrir los gastos del registro (véanse la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 54, apartado i), y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 36).

16. La finalidad de este enfoque puede ilustrarse con el siguiente ejemplo. Una empresa dispone de un bien con un valor estimado de mercado de 100.000 dólares. La empresa solicita la apertura de una línea de crédito por un importe máximo de 50.000 dólares (incluidos capital, intereses y costos). El acreedor está dispuesto a concederle el préstamo a condición de que se le otorgue una garantía real sobre dicho bien. El otorgante consiente en otorgar la garantía, pero dado que el préstamo máximo especificado en el acuerdo de garantía y en la notificación es de 50.000 dólares y el bien tiene un valor de 100.000 dólares, el otorgante desea reservarse la posibilidad de obtener otro préstamo garantizado de otro acreedor con cargo al valor residual del bien. Normalmente, el segundo acreedor será reacio a conceder un préstamo por temor a que el primer acreedor garantizado pueda conceder préstamos más adelante que superen la cantidad inicial de 50.000 dólares, en cuyo caso tendría prelación conforme a la regla general de que prima la garantía inscrita en primer lugar. Al imponerse la obligación de especificar el máximo por el que se puede ejecutar la garantía real, el segundo acreedor puede tener la seguridad de que el acreedor garantizado inscrito en primer lugar no podrá ejecutarla por un monto superior a 50.000 dólares, con lo que quedará disponible el valor residual para resarcir su propio crédito, en el supuesto de que el otorgante incurra en incumplimiento.

17. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce que un enfoque igualmente válido consiste en no exigir la inclusión de un importe máximo en el

acuerdo de garantía y la notificación inscrita. Este enfoque se basa en los siguientes supuestos: a) el primer acreedor garantizado inscrito en el registro será la fuente financiera más satisfactoria a largo plazo o la que ofrecerá más probabilidades de conceder financiación, especialmente a pequeñas empresas en su fase inicial de creación, siempre que ese acreedor tenga la certeza de que conservará su prelación con respecto a toda financiación que conceda al otorgante en el futuro; b) en todo caso, el otorgante no dispondrá de suficiente poder de negociación para exigir que el acreedor garantizado inscrito en primer lugar consigne una suma realista en la notificación (al contrario, el acreedor garantizado insistirá en que se incluya una suma exagerada que cubra todo crédito que en un futuro se otorgue y, por lo general, el otorgante no estará en condiciones de negarse); y c) un segundo acreedor a quien el otorgante solicite financiación estará en condiciones de negociar un acuerdo de subordinación con el acreedor garantizado que se haya inscrito en primer lugar respecto del crédito otorgado con cargo al valor residual que tenga en ese momento el bien gravado.

18. Así pues, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce que ambos enfoques ofrecen ventajas y recomienda que el régimen de las operaciones garantizadas de un Estado promulgante adopte la norma que mejor se ajuste a las prácticas de financiación y del mercado crediticio más eficientes de ese Estado. En el reglamento de los Estados que adopten el primer enfoque se debería incluir una regla que exija al solicitante de la inscripción especificar el importe máximo y la moneda pertinente en el espacio de la notificación inscrita previsto para ello (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 23, apartado a), inciso v); en lo que respecta a las consecuencias de especificar en la notificación inscrita una suma diferente al importe máximo convenido en el acuerdo de garantía, véanse los párrs. 32 a 35 *infra*). No es necesario que esta cuestión se trate en mayor profundidad en el reglamento de los Estados que adoptan el segundo enfoque.

19. Cabe destacar que, en los Estados que adoptan el primer enfoque, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no da lugar a que un Estado promulgante base sus tasas de inscripción en una escala ascendente vinculada al importe máximo especificado en la notificación. Las tasas de inscripción no deben ser superiores a lo requerido para cubrir los gastos del registro (véanse la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 54, apartado i), y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 36).

6. Efecto de los errores u omisiones sobre la validez de la inscripción registral de una notificación

a) Información sobre el otorgante

20. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la inscripción de una notificación solo surta efecto si es posible recuperar la notificación mediante una búsqueda en el fichero del registro utilizando el identificador correcto del otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 66 a 77, y la recomendación 58). El reglamento debería reiterar esta recomendación (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 29, apartado a)). De la última oración de esta recomendación se desprende que un error en el dato de identificación del otorgante proporcionado por el solicitante de la inscripción invalidará el registro de una notificación y, por consiguiente, no se lograría la oponibilidad a terceros de la garantía real, independientemente de que, en abstracto,

el error pueda parecer de escasa importancia o nimio. El único criterio consiste en determinar si el error impediría recuperar la información contenida en el fichero del registro utilizando el identificador correcto del otorgante como criterio de búsqueda.

21. El criterio anteriormente mencionado es objetivo, ya que la inscripción registral no permitirá lograr la oponibilidad a terceros aun cuando un acreedor concurrente que ponga en duda la validez de la inscripción: a) sepa que existe una garantía real y que la notificación conexa contiene errores; y b) no haya resultado perjudicado por el hecho de no haber podido acceder a la notificación (por ejemplo, si el tercero que efectúa una búsqueda es el representante del otorgante en un procedimiento de insolvencia).

22. La *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no incluye ninguna recomendación acerca del efecto sobre la validez de la inscripción registral de un error en la dirección del otorgante o en otros datos complementarios referidos a él (por ejemplo, la fecha de nacimiento o el número de identificación del otorgante) que el Estado promulgante permita o exija incluir a fin de identificar al otorgante de manera más inequívoca (en A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 59 a 61 y 69 a 71, se examina la información complementaria sobre el otorgante). Al igual que el identificador y la dirección del acreedor garantizado, este tipo de información no constituye un criterio de búsqueda. Por consiguiente, por analogía con el criterio recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* con respecto a los errores en los datos personales del acreedor garantizado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 64), el reglamento debería disponer que un error en la dirección del otorgante o en los datos complementarios sobre el otorgante no invalide la inscripción de una notificación, a menos que induzca a error grave al autor razonable de una consulta (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 29, apartado (b)). Por ejemplo, si la búsqueda conduce a numerosos otorgantes, todos ellos con el mismo nombre que la persona en quien está interesado el autor de la consulta, pero el error en la dirección del otorgante o en cualquier dato adicional sobre el otorgante obligatorio es lo suficientemente grave para inducir al autor razonable de una consulta a creer que ninguna de las notificaciones se refiere al otorgante pertinente, la inscripción no se consideraría válida.

23. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no se contempla expresamente la situación en que en una notificación se enumere a más de un otorgante, pero solamente se produzca un error en el identificador de uno de ellos. En ese caso, por analogía con lo que se recomienda en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* con respecto a un error cometido en la descripción de solo algunos de los bienes gravados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 65), el reglamento debería disponer que el error no prive a la notificación inscrita de validez con respecto a otros otorgantes correctamente identificados (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 29, apartado c)).

b) Información sobre el acreedor garantizado

24. Dado que el identificador del acreedor garantizado no constituye un criterio de indexación ni de búsqueda (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párr. 22), la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la indicación incorrecta por parte del autor de una inscripción del identificador o de la dirección del acreedor garantizado o su representante solamente invalidará la inscripción registral si induce a error grave al autor razonable de una consulta (véase la *Guía sobre las Operaciones*

Garantizadas, recomendación 64). Por ejemplo, si el acreedor garantizado real es el Banco A, y en el resultado de una búsqueda efectuada en el archivo del registro a partir del identificador del otorgante figura el Banco B como acreedor garantizado, por lo general la notificación inscrita seguiría siendo válida, dado que del resultado de la búsqueda seguiría deduciéndose la posible existencia de una garantía real concedida por el otorgante nombrado. No obstante, los autores de las consultas se valen del identificador y la dirección del acreedor garantizado que figuran en el archivo del registro para enviar las notificaciones que hayan de dar con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas. Por consiguiente, un acreedor garantizado podría encontrarse en situación de desventaja si los datos sobre el acreedor garantizado que consignó no son exactos. Por ejemplo, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda dar notificación de la enajenación extrajudicial de un bien gravado a cualquier otro acreedor garantizado que haya inscrito una notificación relativa al mismo otorgante y los mismos bienes gravados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 149 a 151). Un acreedor garantizado cuya información no sea exacta se arriesga a no recibir la notificación de la enajenación extrajudicial. Asimismo, la persona que figura como otorgante en la notificación inscrita necesita disponer de esa información para solicitar por escrito al acreedor garantizado la cancelación o la modificación de la notificación si el otorgante no autorizó la inscripción (*Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72, apartado a), y A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. [...]).

c) Descripción de los bienes gravados

i) Observaciones generales

25. De conformidad con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, si el autor de una inscripción no describe un bien gravado en una notificación inscrita, no se obtendrá la oponibilidad a terceros de la garantía real sobre el bien omitido (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 63). Si la descripción es meramente errónea, la equivocación solamente invalidará la inscripción de la notificación si induce a error grave al autor razonable de una consulta (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 64). Aun cuando se omitan los bienes gravados o la descripción induzca gravemente a error, la inscripción solo carecerá de validez con respecto a los bienes omitidos o erróneamente descritos y no con respecto a los bienes que se hayan descrito correctamente (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 65). El reglamento debería contener disposiciones que correspondan a estas recomendaciones (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 29, apartados b) y c)).

ii) Bienes con número de serie

26. Como ya se ha mencionado (véase el párr. 8 *supra*, los bienes gravados que tienen un número de serie podrán describirse en una notificación, a discreción del solicitante de la inscripción, haciendo referencia al número de serie y al tipo de bien, de tal manera que puedan identificarse razonablemente (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 63 y 14, apartado d)). Un error en el número de serie o el tipo de bien debería tratarse como cualquier otro error en la descripción. Por consiguiente, un error leve no debería dejar sin validez una inscripción, a menos que induzca a error grave al autor razonable de una consulta

(véanse la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 64, y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 29, apartado b)).

27. Como se ha mencionado (véase el párr. 7 *supra*), en algunos Estados es preciso especificar en una notificación el número de serie de determinados bienes a efectos de oponibilidad a terceros y prelación con respecto a determinadas clases de terceros que adquieran derechos sobre el bien en cuestión. En los Estados que adoptan este enfoque, una notificación que contenga un número de serie incorrecto solamente surtirá efecto si se puede recuperar mediante una búsqueda en el fichero del registro a partir del número de serie correcto (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 58). En esos Estados, el reglamento también deberá prever las consecuencias de un error en la consignación bien del identificador del otorgante, bien del número de serie. El reglamento debería disponer que ambos se consignen correctamente.

iii) *Plazo de validez de la inscripción registral*

28. Como ya se ha examinado (véase el párr. 14 *supra*), el régimen de las operaciones garantizadas de un Estado promulgante puede ofrecer a los autores de las inscripciones la opción de que ellos mismos determinen el plazo de vigencia de la inscripción (véanse las variantes B y C que se examinan en A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 9 a 15). Si un Estado promulgante adopta este enfoque, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que, si una notificación contiene una declaración incorrecta con respecto al plazo de vigencia, la notificación no debería quedar invalidada, salvo en la medida en que haya inducido a error grave a terceros que hayan confiado en la veracidad de la notificación inscrita (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 66). El reglamento debería incluir una recomendación a ese respecto (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 29, apartado e)).

29. Al ocuparse de la cuestión de la confianza de un tercero con respecto a un error cometido al especificar el plazo de vigencia en una inscripción registral, es preciso distinguir dos situaciones (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 89 a 91). La primera situación se da cuando el error consiste en que el solicitante de la inscripción especifica un plazo demasiado largo. En este caso, los terceros que realicen una consulta no resultarían perjudicados, ya que en cualquier caso se les habría advertido de la posible existencia de una garantía real. La segunda situación se da cuando el error consiste en especificar un plazo demasiado corto. En este caso, la inscripción caducará al vencer el plazo especificado y la garantía real dejará de ser oponible a terceros, a menos que se hubiera obtenido esa oponibilidad antes del lapso por algún otro método (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 46). Como se ha mencionado, si bien el acreedor garantizado puede restablecer la oponibilidad a terceros al inscribir una nueva notificación, su garantía real solamente será oponible a terceros a partir de la fecha en que la nueva inscripción surta efecto (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 47 y 96).

30. De igual modo, al determinar el tipo de error en el importe máximo especificado que puede causar perjuicio a un tercero que confíe en la veracidad de ese dato deben distinguirse dos situaciones (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 96 y 97). Si el solicitante de la inscripción consigna por error en la notificación inscrita una suma mayor que la especificada en el

acuerdo de garantía, es poco probable que un tercero pueda resultar perjudicado, ya que normalmente basará su decisión de adelantar fondos al otorgante en la cuantía especificada en la notificación inscrita; y el otorgante podría obligar al acreedor garantizado a modificar la notificación inscrita para que la suma consignada coincida con la cuantía que se especifica en el acuerdo de garantía. En el caso contrario, cuando el importe máximo especificado en la notificación es inferior al convenido en el acuerdo de garantía, un tercero que consulte el archivo del registro accesible al público y confíe en la veracidad de la información en él consignada para conceder crédito al otorgante podría resultar perjudicado. Por consiguiente, si hay reclamantes concurrentes, el acreedor garantizado solo podrá ejecutar su garantía real hasta la suma especificada en la notificación inscrita. Si no hay reclamantes concurrentes (es decir, si ningún tercero resulta perjudicado por confiar en la veracidad de la información consignada), el acreedor garantizado podría ejecutar su garantía real hasta la suma convenida en el acuerdo de garantía.

31. Cabe señalar que, a diferencia de las situaciones contempladas en la recomendación 29, apartado b), en que el criterio debe ser objetivo (véase el párrafo 21 *supra*), en este caso el criterio de si la equivocación induce a error grave es subjetivo. Todo tercero que impugne la notificación alegando dicha equivocación deberá demostrar que por esa razón fue realmente inducido a error. En este caso, el criterio subjetivo es adecuado, ya que la finalidad del requisito de especificar el importe máximo es asegurar que el otorgante pueda solicitar más crédito sobre la base del valor residual de los bienes que ya estén gravados por una garantía real, sin que el tercero que financia el crédito deba preocuparse por la posibilidad de que el valor de su garantía quede mermado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 96).

iv) *Importe monetario máximo y efecto de un posible error*

32. En el caso de los Estados que optan por exigir que se consigne en la notificación el importe máximo por el cual puede ejecutarse una garantía real, la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que la indicación incorrecta del importe máximo en la notificación inscrita no haga que la notificación pierda su validez, salvo en la medida en que haya inducido a error grave a terceros que hayan confiado en la veracidad de la notificación inscrita (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 66). El reglamento debería incluir una recomendación a ese respecto (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 27, apartado e)).

33. Como en el caso de un error en la indicación del plazo de vigencia de una inscripción (véase el párr. 31 *supra*), el criterio de si la equivocación induce a error grave es subjetivo. Todo tercero que impugne la notificación alegando dicha equivocación debe demostrar que por esa razón fue inducido a error grave. En este caso, el criterio subjetivo es adecuado, ya que la finalidad del requisito de especificar el importe máximo es asegurar que el otorgante pueda solicitar más crédito sobre la base del valor residual de los bienes que ya están gravados por una garantía real, sin que el tercero que otorgue crédito deba preocuparse por la posibilidad de perder su prelación con respecto al primer acreedor garantizado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 96).

34. Así pues, cuando el importe máximo consignado en la notificación es mayor que el importe máximo convenido en el acuerdo de garantía, es improbable que un

segundo acreedor garantizado pueda resultar perjudicado, ya que normalmente basará su decisión de adelantar fondos en el importe especificado en la notificación. El otorgante también estaría protegido en esta situación, ya que podría pedir al acreedor garantizado o, si este no actúa a su debido tiempo, a un órgano judicial o administrativo por procedimiento sumario, que enmiende la notificación para corregir el importe de modo que el otorgante pueda obtener crédito sobre la base del valor residual del bien gravado (véase *la Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72).

35. No obstante, si el importe máximo especificado en la notificación es inferior al importe máximo convenido en el acuerdo de garantía, el segundo acreedor garantizado podría haber adelantado crédito al considerar que podía ejecutar su garantía real con cargo al valor residual del bien tras restar la suma indicada en la notificación. De igual modo, un comprador podría haber adquirido el bien gravado en el convencimiento de que la garantía del acreedor garantizado sobre el bien se limitaba al valor indicado en la notificación. Asimismo, un acreedor judicial podría haber tratado de ejecutar una sentencia a su favor en el convencimiento de que el valor del bien que superaba el importe indicado en la notificación bastaría para satisfacer su reclamación judicial. Por consiguiente, en todos estos casos el acreedor garantizado debería poder ejecutar su garantía real con respecto al tercero solo hasta el importe máximo erróneamente consignado en la notificación inscrita. Cabe señalar que el acreedor garantizado nunca podrá ejecutar su garantía real por un monto superior al que efectivamente se le adeude.

B. Recomendaciones 23 a 29

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las recomendaciones 23 a 29, tal como se reproducen en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.5. El Grupo de Trabajo quizá desee observar también que, por razones de economía, las recomendaciones no se han incluido en el presente documento en esta etapa, pero se incluirán en el texto definitivo.]

(A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23º período de sesiones**ADICIÓN****Índice**

	<i>Párrafos</i>
V. Inscripción de notificaciones de modificación y cancelación	1-41
A. Observaciones generales	1-41
1. Notificaciones de modificación	1-22
2. Notificaciones de cancelación	23-24
3. Efecto de la expiración o cancelación inadvertida de una notificación inscrita	25-27
4. Validez de las notificaciones de modificación o cancelación no autorizadas por el acreedor garantizado	28-37
5. Modificación o cancelación obligatorias	38-41
B. Recomendaciones 30 a 33	
VI. Criterio y resultados de la consulta	42-51
A. Observaciones generales	42-51
1. Criterio de consulta	42-45
2. Resultados de la consulta	46-51
B. Recomendaciones 34 y 35	
VII. Tasas de inscripción y de consulta	52-58
A. Observaciones generales	52-58
B. Recomendación 36	

V. Inscripción de notificaciones de modificación y cancelación**A. Observaciones generales****1. Notificaciones de modificación****a) Observaciones generales**

1. El autor de una inscripción tal vez desee modificar la información consignada en una notificación inscrita por diversas razones, por ejemplo, para corregir un error en una notificación inscrita anteriormente o para actualizar la información

inscrita a fin de reflejar acontecimientos posteriores. Podrá hacerlo presentando al registro una notificación de modificación. En el reglamento se debería dejar en claro que el solicitante de la inscripción es responsable de consignar la información relativa a la modificación de la misma manera prevista en él para presentar la correspondiente a una notificación inicial (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendaciones 19 y 30).

2. El sistema del registro debería concebirse de modo de garantizar que la inscripción de una notificación de modificación no surtiera el efecto de suprimir o sustituir la información inscrita en la notificación inicial y en toda notificación de modificación inscrita con anterioridad. En lugar de ello, la información consignada en la notificación de modificación se debería agregar a la ya inscrita en el registro, de manera que toda búsqueda condujese a la notificación inicial y todas las notificaciones de modificación inscritas con posterioridad a ella.

3. El acreedor garantizado debería estar en condiciones de inscribir en cualquier momento y según procediera una notificación de modificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 73). Algunas modificaciones requieren la autorización del otorgante (por ejemplo, la que se introduzca para señalar que se han agregado bienes gravados o un otorgante, o -si lo exige el régimen de las operaciones garantizadas del Estado promulgante- que ha aumentado el importe por el cual podrá ejecutarse la garantía real a que se refiere la inscripción. En otras modificaciones no se requiere la autorización del otorgante (por ejemplo, las destinadas a registrar un cambio posterior del identificador del otorgante, la cesión de la obligación garantizada, la subordinación voluntaria de la prelación de la garantía real a que se refiere la inscripción, el cambio de dirección del acreedor garantizado o su representante, o la incorporación como otorgante del cesionario de un bien gravado por el otorgante inicial). De cualquier manera, y como ya se señaló, cuando se requiera la autorización del otorgante este podrá darla antes o después de inscribirse la notificación, y un acuerdo escrito de garantía constituye autorización suficiente (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 71, y el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, párr. 60). Por consiguiente, si la modificación se refiere, por ejemplo a la incorporación de nuevos bienes gravados o de un nuevo otorgante, la celebración de un acuerdo escrito de garantía relativo a esos bienes o a ese otorgante nuevos constituirá en sí misma una autorización.

4. Para efectuar una modificación, el solicitante de la inscripción deberá consignar, en los espacios previstos de la notificación de modificación, el número de inscripción de la notificación inicial a que se refiere esa modificación y la información pertinente que se desee consignar en ella (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 30, apartado a)). Como en el caso de una notificación inicial, el registro deberá consignar respecto de toda notificación de modificación la fecha y la hora en que se incorporó en su base de datos la información correspondiente, a fin de que quede disponible para quienes consulten el fichero del registro accesible al público (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 12, y el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 1 a 6). Tal vez el Estado promulgante desee examinar si el sistema registral y el formulario prescrito de la notificación de modificación deberían concebirse de manera tal que el solicitante de la inscripción pudiera modificar en su notificación de modificación un solo elemento de la información (por ejemplo, el identificador del otorgante) o bien varios elementos en una sola notificación de modificación (por

ejemplo, para agregar un otorgante y eliminar algunos bienes gravados). Se recomienda el último enfoque, porque resulta más sencillo y más eficaz en función de los costos (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 30, apartado f)).

5. En los párrafos siguientes se examinan las diversas razones por las que el acreedor garantizado podría inscribir una notificación de modificación y las repercusiones jurídicas de esa inscripción o la ausencia de ella.

b) Cambio posterior del nombre del otorgante

6. Todo cambio del nombre del otorgante indicado en una notificación inscrita (por ejemplo, a raíz de una fusión) puede reducir la utilidad informativa de la inscripción para los terceros que hagan negocios con ese otorgante tras el cambio de su nombre. Como el nombre del otorgante es el principal criterio de indexación y de búsqueda, su nuevo nombre no servirá en una consulta para encontrar esa notificación. En los sistemas de registro en que se utilice como identificador del otorgante su número de identificación permanente y único u otro número oficial expedido por el Estado a efectos de la indexación y consulta de notificaciones inscritas, es menos probable que se plantee este problema, porque ese número suele ser permanente y no estar sujeto a variación. Sin embargo, con arreglo al enfoque recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, el nombre del otorgante es el principal criterio de indexación y de búsqueda; podrá requerirse, cuando sea preciso para identificar debidamente al otorgante, el número de su tarjeta de identidad, pero ese número no se utilizará como criterio de indexación o de consulta (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 58 a 60, A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 59 y 60, y los párrs. 42 a 45, *infra*).

7. Para resolver este problema, en el reglamento y en el formulario prescrito de la notificación de modificación se debería permitir que el acreedor garantizado agregara en esa notificación el nuevo nombre del otorgante. Aunque una garantía real no debería perder ni en general ni retroactivamente su oponibilidad por no presentarse una notificación de modificación, se debería proteger a los terceros que hicieran negocios con el otorgante después del cambio de su nombre pero antes de que se inscribiera la notificación de modificación correspondiente. Por consiguiente, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que, si el acreedor garantizado no inscribe la notificación de modificación dentro de un breve “período de gracia” (por ejemplo, de 15 días) tras el cambio de nombre, se considere inválida su garantía real respecto de compradores, arrendatarios, licenciarios y otros acreedores garantizados que adquieran derechos sobre el bien gravado después del cambio de nombre del otorgante pero antes de haberse inscrito la modificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 61). En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda también que el período de gracia comience a correr a partir de la fecha del cambio de nombre (en algunos Estados se dispone que comience a correr solo a partir de la fecha en que el acreedor garantizado recibe información sobre ese cambio). En el régimen de las operaciones garantizadas del Estado promulgante se debería impartir también orientación sobre lo que significa una modificación del nombre, en particular en el contexto de las fusiones de empresas y con respecto a las consecuencias de que no se efectúe una modificación tras una fusión.

8. Como ya se señaló (véase el párrafo 2, *supra*), el sistema del registro debería concebirse para garantizar que la inscripción de una notificación de modificación no surtiera el efecto de suprimir o sustituir la información consignada en la notificación inicial y en cualquier otra notificación de modificación anterior. De esa manera, toda consulta en que se utilizara como criterio de búsqueda el nombre antiguo o el nuevo del otorgante permitiría recuperar la información inscrita en el registro. Por ello, es importante que el solicitante de la inscripción comprenda que debe consignar el nuevo nombre del otorgante en el espacio previsto en la notificación de modificación para incorporar el identificador de un nuevo otorgante, sin suprimir la información correspondiente al antiguo otorgante. De otra manera, si se realizara en el fichero del registro una búsqueda basada en el antiguo nombre del otorgante no se encontraría esa inscripción, lo que podría afectar la eficacia de la garantía real frente a terceros que hubieran negociado con el otorgante antes del cambio de su nombre, y cuyas consultas podrían basarse por ello en su nombre anterior.

c) Transferencia de un bien gravado

9. Si el otorgante transfiere, arrienda o licencia un bien gravado, el cesionario, arrendatario o licenciataria adquirirá normalmente su derecho sujeto a la garantía real sobre ese bien, en el supuesto de que se haya hecho oponible a terceros (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 79). Si la garantía real se hizo oponible mediante inscripción, ello plantea un problema análogo al del cambio de nombre del otorgante tras la inscripción, que se examinó más arriba. Los terceros que negocian con el bien gravado que esté en posesión del cesionario, arrendatario o licenciataria deberán normalmente consultar el fichero del registro utilizando como criterio de búsqueda el nombre respectivo. Esa búsqueda no conducirá a la notificación inscrita, porque esta se inscribió e indexó por el nombre del otorgante (el cedente, arrendador o licenciante). Para proteger a los terceros que quieran negociar con un bien gravado en posesión del cesionario, arrendatario o licenciataria, el sistema de registro y el reglamento deberían permitir que el acreedor garantizado presentara una notificación de modificación en que se consignara el nombre y la dirección del cesionario, arrendatario o licenciataria como nuevo otorgante.

10. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que el Estado promulgante aborde las consecuencias jurídicas de que el acreedor garantizado no inscriba una notificación de modificación en esa situación, pero deja a discreción del Estado promulgante decidir cuál de los tres enfoques examinados en el comentario debería adoptar (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 78 a 80, y recomendación 62).

11. El primer enfoque es análogo al que se recomienda adoptar en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* ante el cambio de nombre del otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 61, y los párrs. 6 a 8, *supra*). Conforme a ese enfoque, si la notificación inscrita no se modifica para agregar como nuevo otorgante al cesionario, arrendatario o licenciataria, la garantía real no pierde su oponibilidad a terceros en general. Sin embargo, si el acreedor garantizado no inscribe la notificación de modificación dentro de un breve “período de gracia” (por ejemplo, de 15 días), su garantía real no podrá invocarse frente a los compradores, arrendatarios, licenciarios y acreedores garantizados que adquieran derechos sobre el bien gravado después de su transmisión o arrendamiento o de la

concesión de una licencia sobre él pero antes de haberse inscrito la notificación de modificación. El segundo enfoque es similar, con la importante reserva de que el período de gracia para inscribir la notificación de modificación comienza a correr solo en el momento en que el acreedor garantizado toma conocimiento de que el otorgante ha transmitido o arrendado el bien gravado u otorgado una licencia sobre él. El tercer enfoque es diferente, porque la inscripción de la notificación de modificación es puramente optativa, en el sentido de que no realizarla no afecta la oponibilidad a terceros ni la prelación de la garantía real a que se refiere la inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 78 a 80).

12. Sea cual fuere el enfoque que adopte el Estado promulgante, este debería incluir en su reglamento una disposición por la que se permitiera al acreedor garantizado inscribir una notificación de modificación para agregar como otorgante al cesionario, arrendatario o licenciatario del otorgante inicial (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 30, apartado c)). Es decir, incluso si el Estado promulgante adopta el tercer enfoque optativo, el acreedor garantizado debería estar en condiciones de inscribir una modificación de ese tipo si deseara hacerlo. Esa inscripción le brindaría en la práctica cierto grado de protección contra el peligro de que el cesionario, arrendatario o licenciatario pusiera el bien gravado en manos de un nuevo cesionario al que no fuera posible localizar. Además, la inscripción reduciría el riesgo de controversias, porque los prestamistas del cesionario, arrendatario o licenciatario quedarían al corriente de la situación. Sería preciso que el solicitante de la inscripción comprendiera que en los espacios previstos de la notificación de modificación para agregar un otorgante debería consignar el nombre y la dirección del cesionario, arrendatario o licenciatario, sin suprimir la información sobre el otorgante inicial. De lo contrario, si se buscara en el fichero del registro por el nombre del otorgante no se localizaría la inscripción, lo que podría afectar la oponibilidad de la garantía real frente a terceros que hubiesen hecho negocios con el otorgante antes de que el bien gravado se transfiriera, arrendara o licenciara y que por ello, con toda probabilidad, utilizarían el nombre del otorgante cuando consultaran el fichero.

d) Subordinación de la prelación

13. Conforme a lo recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, un acreedor garantizado que tuviese prelación podría renunciar en cualquier momento a esa prelación, unilateralmente o por acuerdo en favor de cualquier otro reclamante concurrente existente o futuro (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 94). Esa subordinación afecta únicamente los derechos del acreedor garantizado subordinante y los del beneficiario de esa subordinación. Por consiguiente, el registro debería admitir la posibilidad de inscribir una notificación de modificación para dar a conocer una subordinación. Sin embargo, esa inscripción debería ser puramente optativa, en el sentido de que no se requiriese para conservar la oponibilidad o la prelación (o la subordinación de esa prelación) de la garantía real a que se refiriese la inscripción.

e) Cesión de la obligación garantizada y transmisión de la garantía real

14. El acreedor garantizado puede ceder la obligación garantizada. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que, conforme a lo previsto en

la mayoría de los ordenamientos jurídicos, una garantía real, en su calidad de derecho accesorio, se transfiera junto con la obligación garantizada, lo que da lugar a que el cesionario de esa obligación pase a ser, en la práctica, el nuevo acreedor garantizado (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 25 y 48, basadas en el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional). Conforme al enfoque recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, no se requiere modificar la notificación inicial para agregar al cesionario como nuevo acreedor garantizado, pues ello no se considera necesario para mantener la validez de la inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 75). Como el identificador del acreedor garantizado no es un criterio de indexación ni de búsqueda, el cambio no inducirá a errores de importancia a quienes consulten el registro.

15. Aunque inscribir una notificación de modificación es optativo, no hacerlo puede perjudicar al nuevo acreedor garantizado (el cesionario). Como ya se señaló, el autor de una búsqueda debe valerse de la información sobre el acreedor garantizado consignada en las notificaciones inscritas para enviar cualquiera de las comunicaciones previstas en el régimen de las operaciones garantizadas (como la notificación de la enajenación extrajudicial de un bien gravado, que el acreedor garantizado debe enviar a los demás acreedores garantizados que hayan inscrito una notificación relativa al mismo otorgante y los mismos bienes gravados; véase *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 149 a 151). Si no se agrega al cesionario como nuevo acreedor garantizado, este no recibirá directamente las notificaciones de ese tipo, y deberá contar con que se las transmita el acreedor garantizado inicial (el cedente).

f) Incorporación de nuevos bienes gravados

16. Por diversas razones, el acreedor garantizado tal vez desee inscribir una notificación de modificación para agregar bienes gravados a los que haya indicado en una notificación inscrita anterior. Por ejemplo, tal vez el otorgante haya acordado conceder una garantía real sobre otros bienes después de haberse inscrito la notificación anterior, o el acreedor garantizado haya omitido inadvertidamente incluir un bien gravado en la notificación inscrita con anterioridad. Para ajustarse a esa posibilidad, el sistema del registro debería permitir que el acreedor garantizado modificara la lista de bienes gravados de su notificación anterior si deseara agregar bienes. Aunque podría lograr el mismo resultado inscribiendo una nueva notificación inicial con respecto a los bienes nuevos, normalmente sería más eficaz inscribir una notificación de modificación, y con ello el plazo de vigencia de la inscripción sería idéntico para los bienes iniciales y los agregados. Sea cual fuere el método elegido, la garantía real sobre los nuevos bienes gravados se hace oponible a terceros solo a partir de la fecha de inscripción en el registro de la notificación de modificación o la nueva notificación, según el caso, para que puedan consultarla los interesados (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 70). El fundamento de este enfoque es que una consulta por terceros del fichero del registro antes de haberse inscrito la notificación de modificación o la nueva notificación no revelaría que los nuevos bienes gravados podrían estar sujetos a una garantía real.

g) Supresión de bienes gravados

17. Por diversas razones, tal vez el acreedor garantizado desee o deba inscribir una notificación de modificación para suprimir bienes gravados de la lista de ellos que figure en la notificación inicial. Por ejemplo, tal vez el otorgante ha pagado parte de la obligación garantizada a condición de que la garantía real se extinga con respecto a determinados bienes; o tal vez la enumeración de los bienes en la notificación inicial era demasiado amplia y el otorgante haya exigido al acreedor garantizado que modificara la notificación inicial para reflejar el verdadero alcance de los bienes gravados (por lo que atañe a la obligación del acreedor garantizado de modificar una notificación inscrita en esta última situación, véanse los párrs. 38 a 41 *infra*). Por consiguiente, el sistema del registro debería permitir que se inscribiera una notificación de modificación por la que se suprimieran determinados bienes que hubiesen figurado como bienes gravados en una notificación anterior.

h) Cambios en la descripción de los bienes gravados

18. El autor de una inscripción tal vez desee inscribir una notificación de modificación para corregir un error en la descripción de los bienes gravados contenida en una notificación anterior. Esa notificación de modificación adquiriría normalmente validez respecto de los bienes a que se refiere solo a partir de la fecha en que se consignara en el fichero del registro y pudiese consultarse, a menos que ese error fuese secundario y la descripción inicial permitiera individualizar razonablemente los bienes gravados incluso sin que se inscribiera una notificación de modificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 63).

19. Tal vez el acreedor garantizado desee también modificar la descripción de los bienes gravados que figure en una notificación anterior por haber cambiado algunas características de esos bienes después de su inscripción. Por ejemplo, si en esa notificación anterior se indicaba que los bienes gravados eran “muebles de madera de cerezo”, pero luego el otorgante los pintó de verde; o si en la notificación anterior se señalaba que los bienes gravados correspondían íntegramente a existencias situadas en una dirección determinada, pero esas existencias se trasladaron luego a otra dirección. Como la descripción contenida en la notificación anterior ya no es exacta, tal vez el acreedor garantizado desee presentar una notificación de modificación para actualizar la descripción. En general, la modificación no se requiere porque sea necesaria para mantener la oponibilidad a terceros de la garantía real a que se refiere la inscripción. Quienes consulten el registro deberán prever que algunos aspectos de la descripción de un bien gravado en una notificación anterior podrán variar por acontecimientos posteriores a la inscripción y que por ello tal vez tengan que ampliar su búsqueda. Por consiguiente, si se inscribe una notificación de modificación para reflejar esos cambios, la fecha de validez de la inscripción con respecto a los bienes gravados a que se refiera seguirá siendo, en general, la fecha de inscripción de la notificación anterior en que figuraba la descripción inicial, siempre que esa descripción hubiese sido correcta en esa fecha.

i) Prórroga del plazo de vigencia de una inscripción

20. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda permitir que el acreedor garantizado prorrogue, notificando al registro una modificación en

cualquier momento antes de su vencimiento, la validez de una notificación inscrita (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 69). Si, por el contrario, se requiriese inscribir una nueva notificación, ello perjudicaría la prelación del acreedor garantizado y la continuidad de la eficacia de su garantía real frente a terceros, porque la nueva notificación adquiriría validez frente a terceros únicamente a partir de la fecha en que se inscribiera.

21. Como ya se señaló (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 7 a 15), los Estados pueden adoptar varios criterios con respecto al plazo de vigencia de una notificación inscrita. En los Estados en que ese plazo se fije por ley (opción A), el sistema de registro debería admitir que al inscribirse una notificación de modificación se prorrogara automáticamente y por un período equivalente la validez de esa inscripción. En los Estados en que se autoriza al solicitante de la inscripción para fijar por cuenta propia el plazo de vigencia (opción B), se debería permitir que en el formulario prescrito de la notificación de modificación el solicitante de la inscripción fijara también la duración del período de prórroga. De ese modo, el autor de una inscripción que estableciera, por ejemplo, un plazo de vigencia de cinco años para la notificación inicial debería estar autorizado para fijar un período de prórroga distinto. En los Estados que permiten al solicitante de la inscripción elegir por cuenta propia el plazo de vigencia, pero con sujeción a un límite máximo (opción C), el sistema de registro debería concebirse de manera que el autor de una inscripción no pudiera fijar un plazo superior a ese límite máximo.

j) Modificación global de la información sobre el acreedor garantizado

22. Tanto el identificador como la dirección del acreedor garantizado pueden cambiar a causa de una fusión de empresas, una venta u otro acontecimiento posterior a la inscripción. Para que pueda modificarse eficazmente la información sobre el acreedor garantizado consignada en toda notificación relacionada con él, el sistema de registro debería permitir que su personal efectuara una modificación global a solicitud del acreedor garantizado, o que este la hiciera directamente (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 31; con respecto a la protección del acreedor garantizado contra modificaciones no autorizadas o fraudulentas, véanse los párrafos 28 a 37 *infra*).

2. Notificaciones de cancelación

23. Como en el caso de una modificación, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda permitir al acreedor garantizado inscribir en cualquier momento una notificación de cancelación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 73). Para hacerlo no se requeriría autorización del otorgante, porque la cancelación no afectaría a este o le beneficiaría. Como ya se señaló, a diferencia de una modificación, una cancelación elimina del fichero del registro accesible al público todas las notificaciones inscritas a que se refiera. La información retirada se archiva por un período prolongado para que pueda recuperarla el personal del registro (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 44 y 45, y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 21).

24. Para facilitar el trámite de inscripción, la única información que su autor debería consignar en el espacio previsto de la notificación de cancelación sería el número de inscripción asignado por el registro a la notificación inicial, que corresponde en forma permanente a ella y a toda notificación conexas posterior

(véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 32; con respecto a la autorización de una notificación de cancelación por los acreedores garantizados, véanse los párrafos 28 a 37 *infra*).

3. Efecto de la expiración o cancelación inadvertida de una notificación inscrita

25. Si por inadvertencia un acreedor garantizado no prorroga el plazo de vigencia de una inscripción antes de que expire o inscribe una notificación de cancelación, ese acreedor garantizado podrá inscribir una nueva notificación inicial. Sin embargo, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que la oponibilidad a terceros y la prelación de la garantía real a que se refiera la nueva notificación, surtan efecto únicamente a partir de la fecha de su inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 47). Por consiguiente, el acreedor garantizado perdería prelación frente a los reclamantes concurrentes cuyos derechos se hicieran oponibles a terceros antes de vencer o cancelarse la inscripción, incluidos los acreedores garantizados concurrentes respecto de los cuales hubiese tenido prelación anteriormente conforme a la regla del orden de inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. V, párrs. 132 a 134, y recomendación 96). Ese enfoque se basa en la política de evitar que los terceros que consulten el registro deban buscar información fuera de él para determinar si alguna vez existió una garantía real (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párr. 123).

26. Algunos Estados adoptan un criterio menos estricto. Conforme a este segundo enfoque, se otorga al acreedor garantizado un breve periodo de gracia tras el vencimiento o la cancelación de su inscripción, para que la renueve y restablezca de ese modo la oponibilidad y la prelación de su garantía real a partir de la fecha de la inscripción inicial. Sin embargo, para proteger a los terceros que intervengan, en el régimen de las operaciones garantizadas de los Estados que adoptan este enfoque se dispone que la garantía real no sea oponible o esté subordinada a los reclamantes concurrentes que hayan adquirido derechos sobre los bienes gravados o adelantado fondos al otorgante tras vencer o cancelarse la inscripción y antes de efectuarse una nueva. El tercer enfoque es idéntico, excepto que no se fijaría un plazo para renovar una inscripción caducada o vencida, a reserva de los derechos de los reclamantes concurrentes intervinientes (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párr. 123).

27. Por una parte, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se reconoce que mediante los enfoques segundo y tercero se protege también a los terceros que consulten el registro. Por la otra, en ella se reconoce también que restablecer la oponibilidad de una garantía puede originar una compleja controversia de “prelación circular”, en la que el acreedor garantizado que la restablezca recupera su prelación frente a un acreedor garantizado concurrente que haya existido antes del vencimiento o la cancelación de la inscripción, pero no respecto de un tercer acreedor garantizado concurrente que haya aparecido en el periodo que medie entre el vencimiento o la cancelación y el restablecimiento de la oponibilidad. Además, para adoptar cualquiera de esos dos enfoques se requiere que el sistema de registro esté configurado de manera de posibilitar la reactivación de la inscripción inicial o una remisión a ella en la notificación de su restablecimiento. Para evitar estas complicaciones, y a fin de mantener un régimen claro y eficaz de inscripción y prelación, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que toda

inscripción vencida o cancelada se reactive únicamente mediante la inscripción de una nueva notificación, lo que significaría que toda garantía real conexa se haría oponible a reclamantes concurrentes solo a partir de la fecha de esa inscripción (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. III, párrs. 124 a 127, y recomendación 47).

4. Validez de las notificaciones de modificación o cancelación no autorizadas por el acreedor garantizado

28. Como ya se señaló (véanse los párrs. 25 a 27 *supra*), conforme a la recomendación 47 de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* si una garantía pierde su oponibilidad al vencer o cancelarse una inscripción, puede restablecerse esa oponibilidad, pero solo a partir de la fecha en que se inscriba una nueva notificación inicial relativa a la garantía real de que se trate. Sin embargo, en la recomendación 47 no parece abordarse la cuestión de si se pierde la oponibilidad cuando el acreedor garantizado no autoriza inscribir la notificación de cancelación. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* tampoco se aborda esa cuestión en el contexto de una notificación de modificación no autorizada, cuyo efecto previsto equivaldría a una cancelación (por ejemplo, si con esa modificación se pretendiera eliminar un bien gravado de la lista de ellos consignada en la notificación inicial, o suprimir a un otorgante). El resto del análisis de la presente sección se aplica también a esas notificaciones de modificación y a las de cancelación.

29. Además, como ya se señaló (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 38 a 40), conforme al apartado d) de la recomendación 55 de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, el registro debería estar obligado a enviar prontamente una copia de la notificación de modificación o cancelación inscrita al acreedor garantizado. Aunque en el comentario de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se explica que esa obligación se impone para que el acreedor garantizado pueda comprobar la legitimidad de la cancelación o modificación, en él no se aborda la cuestión de si los terceros que realicen consultas pueden dar por válida una cancelación o modificación no autorizada (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 52). Además, en la recomendación 71 de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, se aborda en detalle el asunto de la autorización en el contexto de la que dé el otorgante para una notificación inicial o de modificación, pero no en el de la autorización por el acreedor garantizado para inscribir una notificación de modificación o cancelación. Por último, la recomendación 74 de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, conforme a la cual las notificaciones canceladas se deberían retirar del fichero del registro accesible al público, podrá incidir también en la validez de la inscripción de una notificación de cancelación no autorizada (véanse los párrafos 33 y 34 *infra*).

30. Los respectivos ordenamientos jurídicos adoptan distintos enfoques de esta cuestión. En algunos, la inscripción de una notificación de modificación o cancelación no autorizada se considera válida, lo que significa que los terceros que consulten el registro tienen derecho a considerar legítimo su resultado aunque no haya autorización del acreedor garantizado. Este enfoque se basa en la política de evitar que esos terceros deban buscar fuera del fichero del registro para determinar si alguna vez existió una garantía real en caso de haberse cancelado la inscripción, o si se había autorizado una modificación con la que se pretendiera suprimir un bien gravado o el nombre de un otorgante. En esos ordenamientos jurídicos, el sistema de registro se ha concebido de manera de proteger al acreedor garantizado del riesgo de modificaciones o

cancelaciones fraudulentas introducidas por el otorgante o un tercero, mediante la incorporación de un mecanismo de autorización en el trámite para inscribir modificaciones y cancelaciones. Por ejemplo, se asigna a cada acreedor garantizado un código de usuario único, que este debe consignar en toda notificación de modificación o cancelación que presente para su inscripción. Si el acreedor garantizado no protege la confidencialidad de su código de acceso, no tendrá fundamentos para protestar en caso de que un tercero utilice ese número para inscribir una notificación de cancelación o modificación no autorizada.

31. La inscripción de una modificación o cancelación no autorizada podrá deberse también al error de un bufete de abogados u otro tercero proveedor de servicios al que el acreedor garantizado haya contratado para prestarle servicios de inscripción. Por ejemplo, ese acreedor podrá haberle dado instrucciones de que enmiende una notificación y cancele otra, pero el proveedor de servicios cancela erróneamente la que no correspondía. En los ordenamientos que adoptan ese primer enfoque, el acreedor garantizado se expone al riesgo de error de terceros en una situación como la señalada, y se prevé que de hallarse en ella una indemnización exigiría a ese tercero proveedor de servicios o contrataría un seguro. Como se señaló con anterioridad, en los ordenamientos jurídicos que adoptan el primer enfoque se establece también un mecanismo de seguridad intrínseca, que da a los acreedores garantizados la posibilidad de revalidar una notificación inscrita que se hubiera cancelado erróneamente o sin autorización. Conforme a este enfoque, mediante dicha revalidación se restablece, a partir de la fecha de inscripción de la notificación inicial, la oponibilidad de la garantía real correspondiente frente a los terceros que no sean los que hayan adquirido un derecho sobre el bien gravado en el período posterior a la inscripción de la notificación de cancelación pero anterior a su revalidación. En algunos ordenamientos jurídicos se utiliza un enfoque análogo, que se aplica no solo a las cancelaciones, sino también a las modificaciones, erróneas o no autorizadas.

32. En otros ordenamientos jurídicos, la inscripción de una notificación de modificación o cancelación no es válida si no la ha autorizado el acreedor garantizado. La razón de este enfoque es que en dichos ordenamientos cualquiera puede inscribir una notificación de modificación o cancelación si paga las tasas correspondientes. En este tipo de sistemas de registro de libre acceso, se considera más importante proteger al acreedor garantizado que haya inscrito correctamente una notificación inicial del riesgo mayor de modificaciones y cancelaciones no autorizadas o fraudulentas que garantizar que los terceros puedan fiarse plenamente del fichero del registro. Además, en los ordenamientos jurídicos que adoptan este segundo enfoque, se hace recaer en los terceros que realicen consultas el riesgo que suponga toda inscripción no autorizada que efectúe un bufete de abogados u otro tercero que preste servicios al acreedor garantizado. En esta situación, el asunto de la “autorización” dependería normalmente de las normas generales del derecho interno sobre la capacidad de los agentes y representantes de hacer efectivo el compromiso de sus mandantes. Conforme a este segundo enfoque, los terceros que realicen búsquedas no pueden fiarse plenamente del fichero del registro. Sin embargo, ello no significa que no estén a resguardo. Se da por entendido que un tercero prudente se protegerá poniéndose en contacto con el acreedor garantizado para verificar si se ha autorizado o no la modificación o cancelación. En esos ordenamientos jurídicos suele preverse un procedimiento para obligar al acreedor garantizado a responder en caso de que omita hacerlo o se niegue a ello.

33. En los ordenamientos jurídicos que adoptan el segundo enfoque, todas las notificaciones inscritas permanecen en el fichero del registro accesible al público hasta la fecha en que hubiesen expirado de no mediar cancelación, y aunque se inscriba una notificación de cancelación. De ese modo, se prevé que quienes realicen consultas obtendrán del acreedor garantizado confirmación directa de que ha autorizado esa notificación de cancelación. En el sistema de registro previsto en el proyecto de guía sobre el registro (véanse las recomendaciones 20 y 21), y en consonancia con lo señalado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase el cap. IV, párr. 109, y la recomendación 74), las notificaciones deben retirarse del fichero del registro accesible al público cuando se inscriba una notificación de cancelación. Por consiguiente, en el caso de una cancelación no autorizada, si se adoptara el segundo enfoque, los autores de una búsqueda no podrían protegerse poniéndose en contacto con el acreedor garantizado para determinar si ha autorizado inscribir la notificación de cancelación. Como la información consignada en las notificaciones inscritas a que se refiriera esa notificación de cancelación se habría archivado, no tendrían forma de verificar en el fichero del registro accesible al público si había existido anteriormente una garantía real sobre el bien gravado de que se tratara, ni la identidad del acreedor garantizado.

34. Por otra parte, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no se aborda expresamente la cuestión de si el registro está obligado o no a archivar una notificación cuando el acreedor garantizado no hubiera autorizado inscribir la notificación de cancelación. Conforme a la recomendación 74, debería retirarse del fichero del registro accesible al público la información contenida en una notificación inscrita si esa notificación se ha cancelado “conforme a lo previsto en la recomendación 72 o 73”. Con arreglo a esas dos recomendaciones, deberá cancelarse la notificación cuando no se haya constituido una garantía real, esta se haya extinguido o el otorgante no haya autorizado la notificación inscrita. De ese modo, cabe afirmar que el registro no está obligado a archivar las notificaciones conexas pertinentes si el acreedor garantizado no ha autorizado inscribir una notificación de cancelación.

35. Por ello, al parecer no sería incompatible con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* que el Estado promulgante que adoptara el segundo enfoque dispusiera que el registro no está obligado a archivar la información contenida en las notificaciones inscritas si el acreedor garantizado no ha autorizado inscribir una notificación de cancelación. Sin embargo, en un sistema de libre acceso como el previsto con arreglo al segundo enfoque, el registro no tendría forma de verificar si se había autorizado o no inscribir la notificación de cancelación. Aunque el registro podría, sencillamente, abstenerse de archivar las notificaciones inscritas aunque se presentara una notificación de cancelación, ello contravendría la recomendación 74 de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Por ello, para que la aplicación de este segundo enfoque fuese compatible con la recomendación 74, se debería modificar el régimen de libre acceso al registro incorporando en el trámite de inscripción de notificaciones de cancelación un mecanismo para verificar si el acreedor garantizado las ha autorizado o no. Cabe señalar que no bastaría con que el registro se limitara a asignar al acreedor garantizado un código de acceso seguro para la inscripción de cancelaciones. Ello no serviría para detectar notificaciones de cancelación presentadas erróneamente por un tercero proveedor de servicios a quien el acreedor garantizado hubiese revelado ese código de acceso para que efectuara inscripciones en su nombre. El registro debería contar con un medio de verificación

suplementario para establecer que la notificación de cancelación había sido autorizada directamente por el acreedor garantizado. Opcionalmente, el régimen de las operaciones garantizadas podría disponer expresamente que cuando se inscribiera una notificación de cancelación que contuviera el código de acceso del acreedor garantizado se considerara que este había autorizado dicha inscripción.

36. Por último, cabe señalar que de elegirse el segundo enfoque se debería también configurar el sistema de registro para que pudiese recuperar toda notificación inscrita según el nombre del otorgante, incluso si se hubiese inscrito una notificación de modificación por la que se pretendiera suprimir a ese otorgante. De lo contrario, en una búsqueda no se localizaría esa notificación y los terceros no se enterarían de que debían ponerse en contacto con el acreedor garantizado o adoptar otras medidas para determinar si ese acreedor había autorizado esa eliminación.

37. Opcionalmente, el Estado promulgante podría estudiar la aplicación de un tercer enfoque, de transacción, conforme al cual el autor de una consulta que se fiara en la práctica del fichero del registro estaría resguardado aunque no se hubiese autorizado la inscripción de una modificación o cancelación, pero la garantía real correspondiente conservaría su oponibilidad frente a otros terceros. Mediante ese tercer enfoque se protegería al comprador o al acreedor garantizado que entablara una operación con el otorgante confiando en la legitimidad del resultado de la búsqueda. Sin embargo, ese acreedor garantizado podría de cualquier modo invocar la falta de autorización de la inscripción ante terceros, como el representante de la insolvencia nombrado por el otorgante, que no se remitieran en la práctica al fichero del registro en el sentido de que entablaran una determinada operación basándose en el supuesto de que, por haberse inscrito una notificación de cancelación o modificación, el bien pertinente no estaba gravado.

5. Modificación o cancelación obligatorias

38. Como ya se señaló (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 16 a 18), en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda permitir que una inscripción se efectúe antes de constituirse la garantía real a que se refiere o de concertarse un acuerdo de garantía entre las partes (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 67). Si las negociaciones fracasan después de inscribirse la notificación, o si por alguna otra razón las partes no conciertan un acuerdo de garantía, podrá verse afectada la calificación crediticia de la persona que figure como otorgante en la notificación inscrita. Lo mismo ocurriría si se hubiese concertado un acuerdo de garantía entre el acreedor garantizado y el otorgante cuyo nombre figurase en una notificación inscrita, pero se hubiera suspendido definitivamente su arreglo de financiación garantizada, o una parte de la información consignada en la notificación inscrita superara el alcance de la que hubiese autorizado inscribir el otorgante (por ejemplo, si la descripción de los bienes gravados en esa notificación inscrita fuese más amplia que lo autorizado por el otorgante en el acuerdo de garantía). Por consiguiente, en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda imponer al acreedor garantizado la obligación legal de inscribir en el registro la necesaria notificación de cancelación o modificación, según proceda. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda también que si el acreedor garantizado no lo hace, se conceda al otorgante el derecho de presentarle una solicitud oficial, y que el Estado

promulgante entable un procedimiento judicial o administrativo de carácter sumario para exigir la cancelación o la modificación en caso de que el acreedor garantizado no responda a la solicitud (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72).

39. Para aplicar esas recomendaciones, en el régimen de las operaciones garantizadas o el reglamento del Estado promulgante se debería disponer que el acreedor garantizado tiene la obligación de inscribir una notificación de modificación o cancelación, según proceda, en los casos en que: a) el otorgante no haya autorizado la inscripción de la notificación inicial o de modificación en absoluto o no lo haya hecho en la medida descrita en la notificación; b) la autorización haya sido retirada y no se haya concertado ningún acuerdo de garantía; c) el acuerdo de garantía haya sido revisado de manera que la información contenida en la notificación inscrita resulte inexacta; o d) la garantía real a que se refiere la notificación inscrita se haya extinguido por pago o alguna otra razón y no haya obligación de conceder nuevo crédito (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 33, apartado a)).

40. Si el acreedor garantizado no cumple esa obligación por propia iniciativa, en el régimen de las operaciones garantizadas o el reglamento se le debería imponer la de inscribir la notificación de modificación o cancelación pertinente en un plazo breve después de haber recibido una solicitud escrita del otorgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72, apartado a), y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 33, apartado c)). Ante la posibilidad de que el acreedor garantizado omitiera responder a la solicitud del otorgante o se negara a hacerlo, se debería conceder a este el derecho de solicitar un mandamiento para la inscripción obligatoria de la notificación de cancelación o modificación mediante un procedimiento judicial o administrativo expedito y económico, en que se previeran salvaguardias apropiadas para el acreedor garantizado en caso de que el otorgante formulara exigencias injustificadas (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 72, apartado b), y el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 33, apartado e)).

41. Según la opción que elija el Estado promulgante para su régimen de las operaciones garantizadas o su reglamento, el personal del registro podría inscribir una modificación o cancelación obligatorias a solicitud del otorgante o de un funcionario judicial o administrativo designado por el Estado promulgante. En ambos casos, el mandamiento judicial o administrativo correspondiente debería adjuntarse a la notificación de modificación o cancelación que se presentara al registro (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 33, apartado g)).

B. Recomendaciones 30 a 33

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las recomendaciones 30 a 33, tal como se reproducen en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.5. El Grupo de Trabajo quizá desee observar también que, por razones de economía, las recomendaciones no se han incluido en el presente documento en esta etapa, pero se incluirán en el texto definitivo.]

VI. Criterio y resultados de la consulta

A. Observaciones generales

1. Criterio de consulta

42. Como ya se explicó (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 21 a 23), conforme al criterio recomendado en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, la información que consta en el fichero del registro debe indexarse, u organizarse de otra forma, para que pueda consultarse por remisión al identificador del otorgante. Por consiguiente, en el reglamento se debería disponer que ese identificador fuera el principal criterio de consulta y recuperación de la información inscrita (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 34, apartado a)).

43. El registro debería permitir también que se buscaran y recuperaran notificaciones según el número de inscripción único asignado permanentemente a la notificación inicial y a toda otra conexas y posterior (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 34, apartado b)). Este enfoque permitiría a los autores de inscripciones utilizar un criterio de búsqueda opcional para recuperar con rapidez y eficacia una inscripción a efectos de inscribir una modificación o cancelación. Por consiguiente, en el reglamento se debería disponer que el número de inscripción asignado a la notificación inicial constituye un criterio de consulta opcional (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 34, apartado b)).

44. Como ya se señaló (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 24 a 27), en algunos Estados se requiere consignar en la notificación inicial el número de serie de determinados bienes gravados de alto valor para que la garantía real conexas sea oponible o tenga prelación frente a determinados tipos de reclamantes concurrentes. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se examina ese enfoque, pero sin formular recomendaciones sobre él (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 34 a 36). Si un Estado promulgante decide aplicar este enfoque, en el reglamento se debería impartir orientación respecto de lo que constituye el número de serie correcto de las categorías indicadas de bienes identificados por números de serie, así como disponer que dicho número sea un criterio de consulta optativo.

45. Como ya se señaló (véase el párr. 22 *supra*), el acreedor garantizado debería estar en condiciones de modificar con facilidad su identificador o su dirección, directamente o por conducto del personal del registro y mediante una sola modificación global, en todas las notificaciones inscritas que guardasen relación con él. Sin embargo, el identificador del acreedor garantizado no debería servir como criterio de consulta para el público en general. Ese dato es de escasa pertinencia para los objetivos jurídicos del sistema de registro. Además, si se permitiera su utilización en consultas públicas podrían defraudarse las expectativas razonables de los acreedores garantizados, por ejemplo, al crear el riesgo de que una entidad crediticia realizara una búsqueda basada en el identificador del acreedor garantizado para obtener las listas de clientes de sus competidores (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 81).

2. Resultados de la consulta

46. El reglamento debería disponer que en el resultado de la consulta se indicara, según el caso, que no se encontraron notificaciones inscritas ajustadas al criterio de consulta, o se consignara toda la información de cada notificación inscrita que se ajustara a ese criterio (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 35, apartado a)). El autor de una consulta podrá fiarse de la exactitud de sus resultados únicamente si ha ingresado el identificador correcto del otorgante o ha utilizado otro criterio de búsqueda (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 35, apartado b)).

47. Como ya se señaló (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3, párrs. 20 a 23), la inscripción de una notificación es válida únicamente si al consultar el fichero de registro esa notificación puede recuperarse utilizando como criterio de búsqueda el identificador correcto del otorgante. Algunos sistemas de registro solo pueden localizar las notificaciones inscritas si el identificador del otorgante consignado en ellas corresponde exactamente al que señale el autor de la consulta. Cuando las notificaciones inscritas se almacenan en una base de datos electrónica, en algunos sistemas se programa la lógica de búsqueda de manera que en los resultados aparezcan también las notificaciones inscritas en que el identificador del otorgante se aproxime mucho al que indique el autor de la búsqueda.

48. En los sistemas de registro cuya consulta arroje resultados tanto exactos como aproximados, podrá considerarse válida una inscripción aunque su autor haya cometido un pequeño error al consignar el identificador correcto del otorgante, si la búsqueda conduce efectivamente a una inscripción que contenga ese pequeño error (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3, párrs. 20 y 21). Ello se debe a que toda búsqueda basada en el identificador correcto del otorgante podrá conducir (si la lógica de búsqueda lo permite) a una inscripción que aparezca entre los resultados como correspondencia inexacta pero aproximada. Que el error invalide o no esa inscripción dependerá de factores como los siguientes: a) que el autor de la consulta pueda identificar fácilmente al otorgante remitiéndose a otra información, como la dirección de ese otorgante o cualquier otra que exija suministrar el Estado promulgante, como la fecha de nacimiento o el número de identificación del otorgante; y b) que la lista de correspondencias inexactas no sea tan larga que impida al autor de la consulta determinar razonablemente si el otorgante que le interesa figura en esa lista.

49. Al decidir si entre los resultados de la búsqueda han de figurar también correspondencias aproximadas, el Estado promulgante debería tener presente que, si bien el sistema que las admitiera podría proteger al solicitante de la inscripción de las consecuencias de pequeños errores al consignarse el identificador del otorgante, crearía mayor incertidumbre para los autores de consultas. Por ello, de utilizarse ese sistema tal vez sería necesario recurrir a los tribunales para que establecieran si, en tales circunstancias, el autor de la consulta hubiese debido determinar razonablemente que los resultados de una búsqueda que contenían inscripciones en que el identificador del otorgante figuraba como dato aproximado se referían al otorgante que le interesaba. Por consiguiente, en el reglamento se debería disponer que los resultados de una consulta revelaran información consignada en notificaciones inscritas en que el identificador del otorgante correspondiera exactamente al que indicase el autor de la búsqueda. Si el sistema de registro permitiera también incluir en esos resultados información contenida en

notificaciones inscritas en que el identificador del otorgante se aproximara mucho al utilizado en la consulta, se deberían enunciar con claridad las reglas para determinar lo que constituye una correspondencia suficiente (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 35, apartado b)). En algunos Estados, cuando en una búsqueda realizada mediante el programa informático del registro se obtiene una inscripción que contenga un pequeño error, se considera de cualquier modo que la correspondencia es suficiente.

50. En el reglamento se debería disponer también que, si el autor de una consulta lo solicita y, si procede, paga las tasas correspondientes, el registro expedirá un certificado oficial de consulta en el que se indique el resultado de la búsqueda (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 33, apartado c)). En el caso de una búsqueda electrónica, ese certificado de consulta podría ser sencillamente una versión impresa del resultado de la búsqueda. La cuestión de la admisibilidad de ese certificado ante un tribunal y la de su eventual valor probatorio incumbe al derecho procesal del Estado promulgante. Sin embargo, en principio el certificado de consulta sería admisible como prueba presuntiva de su contenido. Correspondería luego a la parte que impugnara ese certificado presentar pruebas en contrario (por ejemplo, que demuestren que el certificado de consulta es falso, o que refleja de manera inexacta o incompleta el resultado de la búsqueda a que se refiere).

51. En algunos sistemas de registro se asigna a los resultados de la búsqueda una “fecha de validez”, la cual indica que el resultado de la búsqueda contiene únicamente la información consignada en notificaciones inscritas hasta esa fecha (y no hasta la fecha efectiva del resultado de la búsqueda). Esa “fecha de validez” se asigna a los resultados de búsquedas realizadas en sistemas de registro en los que la inscripción de una notificación surte efecto legal en la fecha y hora en que dicha notificación se presenta al registro. Su finalidad es advertir a los autores de consultas sobre la posibilidad de que se haya presentado al registro una inscripción legalmente válida en el lapso entre la “fecha de validez” y la fecha efectiva de la búsqueda. Como ya se señaló (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 1 a 6), en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que la inscripción surta efecto legal solo a partir del momento en que la información consignada en la notificación que se presente al registro se inscriba en el fichero del registro de modo que pueda consultarse públicamente (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párrs. 102 a 105, y la recomendación 70). Por consiguiente, en el sistema de registro previsto en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* no sería necesario indicar la “fecha de validez” en el resultado de la búsqueda, porque esa fecha sería de dicha búsqueda.

B. Recomendaciones 34 y 35

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar las recomendaciones 34 y 35, tal como se reproducen en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.5. El Grupo de Trabajo quizá desee observar también que, por razones de economía, las recomendaciones no se han incluido en el presente documento en esta etapa, pero se incluirán en el texto definitivo.]

VII. Tasas de inscripción y de consulta

A. Observaciones generales

52. En la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se recomienda que las tasas de inscripción y de consulta no se destinen a incrementar los ingresos del Estado promulgante, sino que, más bien, se fijen meramente en una cuantía suficiente para la recuperación de gastos (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, cap. IV, párr. 37, y la recomendación 54, apartado i)). El fundamento de este enfoque es que el cobro de tasas e impuestos excesivos desalentaría considerablemente la utilización del registro, lo que reduciría la eficacia general del régimen de las operaciones garantizadas del Estado promulgante. Para evaluar el monto en que deberían fijarse las tasas de inscripción para recuperar los gastos, se deberían tener en cuenta no solo los costos iniciales del establecimiento del registro, sino también sus gastos de funcionamiento, como los siguientes: a) sueldos del personal; b) modernización y reposición de equipo físico y programas informáticos; c) capacitación permanente del personal y d) actividades promocionales y de capacitación destinadas a los usuarios del registro.

53. Los avances de la tecnología de la información han reducido la diferencia entre los costos iniciales relativos de establecer un registro electrónico y los de crear uno basado en documentos impresos. Además, los gastos de funcionamiento del primero son menores, especialmente si el sistema permite a los autores de inscripciones y consultas presentar directamente por vía electrónica notificaciones y solicitudes de consulta sin que la intervenga el personal del registro. Si el fichero del registro electrónico se establece en colaboración con una empresa privada, esta podrá efectuar la inversión inicial de capital en la infraestructura y recuperarla luego cobrando un porcentaje de las tasas que paguen los usuarios del registro una vez que este se halle en funcionamiento.

54. En algunos Estados, para alentar la utilización del registro por los acreedores, no se cobran tasas de inscripción o estas se fijan en una cuantía muy baja, inferior incluso a lo necesario para recuperar los gastos de inscripción. Aunque de esa manera puede alentarse a los acreedores a que constituyan e inscriban garantías reales en relación con operaciones de poca cuantía y otras que de lo contrario podrían realizarse sin garantías de seguridad, ello significa que el registro y los beneficios que reporta a los acreedores se subsidian con los impuestos generales que pagan los contribuyentes. En otros Estados, solo es gratuito inscribir notificaciones de cancelación, y que lo sea tiene por objeto alentar a los acreedores garantizados a que inscriban sin tardanza sus notificaciones de cancelación una vez concluida su relación financiera garantizada con el otorgante. Por fin, en otros Estados es gratuita la búsqueda (pero no la inscripción) electrónica.

55. Como ya se señaló (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, párrs. 9 y 10), el Estado promulgante podrá autorizar al solicitante de la inscripción para fijar por cuenta propia el plazo de vigencia de una notificación inscrita. El Estado que adopte ese criterio tal vez desee examinar si las tasas de inscripción deberían basarse en una escala móvil relacionada con el plazo de vigencia fijado por el solicitante de la inscripción. Este enfoque tiene la ventaja de que desalentaría a los acreedores garantizados de fijar en la notificación inscrita un plazo demasiado largo por exceso de cautela.

56. Como se señaló con anterioridad (véase el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.3, párrs. 15 a 19), el Estado promulgante podrá optar por exigir que en la notificación inscrita se indique la cuantía máxima por la que podrá ejecutarse una garantía real. En los Estados que adoptaran ese enfoque, las tasas de inscripción que cobrara el registro no deberían fijarse en función de esa cuantía máxima indicada en la notificación, porque ello contravendría el criterio de ceñir la cuantía de las tasas a lo necesario para recuperar los gastos que se recomienda aplicar en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* (véase el párr. 52 *supra*).

57. Toda tasa de inscripción y de consulta que fijara el Estado promulgante debería estipularse en el reglamento (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 36). Corresponderá a cada Estado promulgante decidir si en este contexto se entenderá por “el reglamento” una normativa oficial o directrices administrativas de carácter más oficioso que pudieran ser modificadas por el registro. Este último enfoque permitiría actuar con mayor flexibilidad para ajustar las tasas en caso de que posteriormente se pudiese, por ejemplo, reducir las al haberse recuperado la inversión inicial. Sin embargo, ese enfoque tiene la desventaja de que por no tratarse de una norma oficial el registro podría aplicarla arbitrariamente para aumentar sin justificación la cuantía de las tasas.

58. En un sistema híbrido, basado a la vez en documentos impresos y electrónicos, tal vez sería razonable que el Estado promulgante fijara tasas más elevadas para la tramitación de notificaciones y solicitudes de consulta impresas, porque esa labor correspondería al personal del registro, que no tendría que ocuparse de las presentadas por vía electrónica. Además, ello alentaría con el tiempo a los usuarios a utilizar exclusivamente las funciones de inscripción y consulta electrónica directas.

B. Recomendación 36

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la recomendación 36, tal como se reproduce en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.5. El Grupo de Trabajo quizá desee observar también que, por razones de economía, la recomendación no se ha incluido en el presente documento en esta etapa, pero se incluirá en el texto definitivo.]

(A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.5) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23º período de sesiones**ADICIÓN****Índice***Recomendaciones*

Anexo I. Terminología y recomendaciones	
Terminología	
Recomendaciones	
I. Registro y director del registro	1-3
II. Acceso a los servicios del registro	4-10
III. Inscripción registral	11-22
IV. Inscripción de notificaciones iniciales	23-29
V. Inscripción de notificaciones de modificación y cancelación	30-33
VI. Consultas	34-35
VII. Tasas	36

Anexo I**Terminología y recomendaciones****Terminología***

a) Por “dirección” se entenderá: i) una dirección física, con nombre y número de calle, ciudad, código postal y Estado; ii) un número de apartado postal, ciudad, código postal y Estado; iii) una dirección electrónica; o iv) una dirección que sirva para comunicar información;

b) Por “modificación” se entenderá el cambio de la información consignada en una notificación inscrita previamente en el registro a la que se refiera la modificación;

c) Por “cancelación” se entenderá la retirada del fichero del registro accesible al público de la información consignada en todas las notificaciones inscritas previamente en el registro a las que se refiera la cancelación;

* La sección B de la introducción de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* sobre terminología e interpretación es aplicable también al proyecto de guía sobre el registro, complementada por la sección correspondiente a terminología e interpretación de la introducción del proyecto de guía sobre el registro.

d) Por “espacio previsto” se entenderá el espacio en el formulario de notificación prescrito designado para consignar el tipo de información especificado;

e) Por “otorgante” se entenderá la persona identificada en la notificación como otorgante;

f) Por “ley” se entenderá la ley del Estado promulgante que rija las garantías reales sobre bienes muebles;

g) Por “notificación” se entenderá toda comunicación escrita (consignada en papel o electrónica) enviada al registro de información en relación con una garantía real; la notificación podrá ser una notificación inicial, una notificación de modificación o una notificación de cancelación;

h) Por “solicitante de la inscripción” se entenderá la persona que presenta una notificación al registro para su inscripción [y que puede ser el acreedor garantizado o un tercero proveedor de servicios];

i) Por “director del registro” se entenderá la persona nombrada con arreglo a la ley y el reglamento para que supervise y administre el funcionamiento del registro;

j) Por “inscripción” se entenderá la incorporación en el registro [el fichero] [la base de datos] de la información consignada en una notificación;

k) Por “número de inscripción” se entenderá el número único asignado por el registro a una notificación inicial y permanentemente asociado a esa notificación y toda notificación conexas;

l) Por “fichero del registro” se entenderá la información contenida en todas las notificaciones inscritas que se almacena electrónicamente en el registro [el fichero] [la base de datos] y que consta del fichero a disposición del público (fichero del registro accesible al público) y el fichero que se ha suprimido del fichero del registro accesible al público (archivos del registro);

m) Por “reglamento” se entenderá el conjunto de reglas que aplique el Estado promulgante respecto del registro, tanto si dichas reglas figuran en directrices administrativas o en la ley sustantiva sobre las operaciones garantizadas; y

n) Por “acreedor garantizado” se entenderá la persona indicada en la notificación como el acreedor garantizado [y podrá ser el acreedor garantizado o su representante].

Recomendaciones

I. Registro y director del registro

Recomendación 1. Establecimiento del registro

El reglamento debería disponer que el registro se establezca con el fin de recibir, almacenar y hacer accesible al público la información consignada en las notificaciones inscritas respecto de garantías reales sobre bienes muebles.

Recomendación 2. Nombramiento del director del registro

El reglamento debería disponer que [la persona autorizada por el Estado promulgante o por la ley del Estado promulgante] designe al director del registro, especifique las funciones del director del registro y supervise el desempeño del director del registro.

Recomendación 3. Funciones del registro

El reglamento debería disponer que el registro cumpla, entre otras, las siguientes funciones:

a) Ofrezca acceso a sus servicios de conformidad con las recomendaciones 4, 6, 7 y 9;

b) Dé publicidad a los medios de acceso a los servicios del registro y los días y horas de apertura de cualquier oficina del registro de conformidad con la recomendación 5;

c) Haga saber los motivos del rechazo de una inscripción de una notificación o una solicitud de consulta de conformidad con las recomendaciones 8 y 10;

d) Incorpore en el registro [el fichero] [la base de datos] la información consignada en una notificación presentada al registro, y registre la fecha y hora de cada inscripción, de conformidad con la recomendación 11, y asigne un número de registro a la notificación inicial de conformidad con la recomendación 12;

e) Indexe u organice de alguna otra manera la información consignada en el fichero del registro con el fin de que pueda ser consultada, de conformidad con la recomendación 16;

f) Proporcione a los autores de una inscripción y a los acreedores garantizados un ejemplar de la notificación inscrita, de conformidad con la recomendación 18;

g) Incorpore la información consignada en una notificación de modificación en el registro [el fichero] [la base de datos], de conformidad con la recomendación 19;

h) Retire la información contenida en una notificación inscrita del fichero del registro accesible al público cuando expire su período de vigencia o se inscriba una notificación de cancelación, de conformidad con la recomendación 20;

- i) Archive la información retirada del fichero del registro accesible al público de conformidad con la recomendación 21; y
- j) Proteja la integridad de la información consignada en el fichero del registro de conformidad con la recomendación 17, apartado b).

II. Acceso a los servicios del registro

Recomendación 4. Acceso del público a los servicios del registro

El reglamento debería disponer que toda persona pueda presentar una notificación o una solicitud de consulta al registro [de conformidad con la recomendaciones 6 y 9].

[Nota para el Grupo de Trabajo: Para ayudar al lector a comprender la relación mutua entre la recomendación 4, por una parte, y las recomendaciones 6 y 9 por la otra, y para evitar crear inadvertidamente una incompatibilidad entre ellas, el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de conservar el texto entre corchetes.]

Recomendación 5. Días y horarios de funcionamiento del registro

El reglamento debería disponer que:

- a) Si el acceso a los servicios del registro se ofrece a través de una oficina tradicional:
 - i) Cada oficina del registro esté abierta al público durante [los días y horarios que especifique el Estado promulgante]; y
 - ii) La información acerca de la ubicación de las oficinas del registro y sus días y horarios de atención al público se publiquen en el sitio web del registro, si lo hubiere, o ampliamente de alguna otra manera, y los días y horarios de apertura de cada oficina se anuncien visiblemente en ella;
- b) Si el acceso a los servicios del registro se ofrece a través de medios de comunicación electrónicos, el acceso esté disponible en todo momento; y
- c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b) de esta recomendación:
 - i) El registro pueda suspender total o parcialmente el acceso a los servicios que presta durante un plazo que sea lo más breve posible; y
 - ii) La notificación de la suspensión de los servicios y su duración prevista se publique con antelación, cuando sea viable, y, de no serlo, lo más pronto que sea razonablemente posible en el sitio web del registro, si lo hubiere, o ampliamente de alguna otra manera, y, si el registro facilita el acceso a sus servicios a través de locales de oficinas, la notificación se coloque visiblemente en cada oficina.

Recomendación 6. Acceso a los servicios de inscripción registral

El reglamento debería disponer que toda persona pueda presentar una notificación [inicial] para su inscripción siempre que esa persona:

- a) Utilice el formulario que prescriba el registro;
- b) Acredite [facilite información sobre] su identidad de la manera prescrita por el registro; y
- c) Haya abonado, o haya adoptado medidas para abonar, a satisfacción del registro, todas las tasas que prescriba el registro.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de mantener: a) el texto entre corchetes en el párrafo introductorio, ya que “notificación” incluye también la notificación de una modificación o de una cancelación y los procedimientos del registro pueden imponer determinadas limitaciones (por ejemplo, exigir que se marque un código de seguridad asignado al solicitante de la inscripción de la notificación inicial) en relación con las personas que puedan inscribir una notificación de modificación o de cancelación; y b) las palabras entre corchetes en el apartado b), habida cuenta del hecho de que una persona facilita información (por ejemplo, un ejemplar de un documento), pero no su identidad propiamente dicha, o una redacción alternativa similar a “se identifique” o “demuestre su identidad” siempre que se explique que no se exigirá una verificación de la identidad más allá de lo que se prevé en la recomendación 7.]

Recomendación 7. No se exige la verificación de la identidad ni prueba de la existencia de una autorización ni el examen a fondo del contenido de la notificación

El reglamento debería disponer que:

- a) El registro mantenga [información sobre] la identidad del solicitante de la inscripción pero no exija su verificación;
- b) El registro no exija prueba de la existencia de una autorización para inscribir la notificación; y
- c) El registro no lleve a cabo otro examen a fondo del contenido de la notificación. En particular, no incumbirá al registro velar por que la información incorporada en un espacio previsto sea completa, precisa y jurídicamente suficiente.

[Nota para el Grupo de Trabajo: Al examinar el texto entre corchetes que figura en el apartado a) de esta recomendación, el Grupo de Trabajo tal vez desee observar que la referencia al hecho de que el registro mantenga información significaría preservar en sus ficheros la información presentada por el solicitante de la inscripción sobre su identidad (por ejemplo una copia de una tarjeta de identidad o un permiso de conducir o una ficha de la información pertinente sobre esos documentos).]

Recomendación 8. Rechazo de una solicitud de inscripción de una notificación

El reglamento debería disponer que:

- a) El registro pueda rechazar la inscripción de una notificación que se le presente para su inscripción si el solicitante de la inscripción no incorporó información en todos los espacios previstos requeridos o si la información incorporada es ilegible; y
- b) El registro dé los motivos del rechazo de la inscripción de una notificación presentada al registro tan pronto como sea factible.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que en el comentario se explica que, en el caso de un registro electrónico, la expresión “tan pronto como sea factible” debería significar “casi de inmediato”, mientras que, en el caso de un registro en que se puedan presentar notificaciones en papel, la expresión significará “lo antes posible habida cuenta de las circunstancias”.]

Recomendación 9. Acceso a los servicios de consultas

El reglamento debería disponer que toda persona pueda presentar una solicitud de consulta, si esa persona:

- a) Utiliza el formulario prescrito por el registro; y
- b) Ha abonado, o ha adoptado medidas para abonar, a satisfacción del registro, todas las tasas que prescriba el registro.

Recomendación 10. Rechazo de una solicitud de consulta

El reglamento debería disponer que:

- a) El registro pueda rechazar una solicitud de consulta si en ella no se presenta un criterio de consulta de manera legible; y
- b) El registro dé los motivos del rechazo de una solicitud de consulta tan pronto como sea factible.

III. Inscripción registral

Recomendación 11. Momento de validez de la inscripción de una notificación

El reglamento debería disponer que:

- a) La inscripción de una notificación sea válida a partir de la fecha y hora en que la información consignada en la notificación se incorpore al registro [al fichero] [a la base de datos] de modo que quede disponible para quienes consulten el fichero del registro accesible al público;
- b) El registro mantenga una constancia de la fecha y hora en que cada notificación se incorpora al registro [al fichero] [a la base de datos] de modo que quede a disposición de quienes consulten el fichero del registro accesible al público; y
- c) El registro incorpore en el registro [el fichero] [la base de datos] e indexe u organice de otra manera la información consignada en una notificación presentada al registro para su inscripción de modo que quede a disposición de quienes consulten el fichero del registro accesible al público lo antes posible o dentro de [un breve plazo que deberá especificar el Estado promulgante] y en el orden en que la notificación fue presentada al registro.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que, en el apartado c) de esta recomendación, las palabras “lo antes posible” sustituyeron a las palabras “de inmediato”: a) teniendo en cuenta que, incluso en el caso de un registro electrónico, las notificaciones inscritas podrían consultarse casi de inmediato; y b) en aras de la coherencia con la redacción de la

recomendación 8, apartado b). Si el Grupo de Trabajo decide retener esta nueva redacción, tal vez desee incluir en el comentario una explicación parecida a la explicación que figura en la nota de la recomendación 8 y suprimir la redacción alternativa (“o dentro de ...”).]

Recomendación 12. Número de inscripción

El reglamento debería disponer que el registro asigne un número único de inscripción a toda notificación inicial [y que a todas las notificaciones relativas a esa notificación inicial se les asigne el mismo número].

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee retener el texto entre corchetes. Aunque parece que repite la idea central del texto empleado en la explicación de este término en la terminología, puede que sea necesario (o útil): a) ya que el texto adopta la forma de una guía y la terminología forma parte del comentario (no reglamentos con definiciones); y b) incluso si el texto adoptara la forma de reglamento con definiciones, habría que establecer una distinción entre definiciones y normas dispositivas.]

Recomendación 13. Plazo de validez de la inscripción de una notificación

El reglamento debería disponer que:

Variante A

a) Toda inscripción de una notificación inicial sea válida durante [el Estado promulgante deberá insertar el plazo especificado en su ley];

b) El plazo de vigencia se pueda prorrogar durante [un plazo suplementario establecido en la ley del Estado promulgante] en cualquier momento antes de su expiración. El nuevo plazo comienza cuando el plazo en curso expire; y

[c) Una notificación de modificación que no sea una notificación de modificación mencionada en el apartado b) de esta recomendación no prorroga el plazo de vigencia.]

Variante B

a) La inscripción de una notificación inicial sea válida durante el plazo indicado en el espacio previsto en la notificación;

b) El plazo de vigencia se pueda prorrogar o reducir, en cualquier momento antes de que expire, por el plazo indicado en una notificación de modificación. En el caso de una prórroga, el nuevo plazo comienza en el momento en que expire el plazo en curso; y

[c) Una notificación de modificación que no sea una notificación de modificación mencionada en el apartado b) de esta recomendación no prorroga el plazo de vigencia.]

Variante C

a) La inscripción de una notificación inicial sea válida durante el plazo indicado en el espacio previsto en la notificación, que no sea superior a [un

plazo prolongado, como, por ejemplo, 20 años, que deberá especificar el Estado promulgante];

b) El plazo de vigencia se pueda prorrogar o reducir por el plazo indicado en una notificación de modificación, que no sea superior a [un plazo prolongado, como, por ejemplo, 20 años, que deberá especificar el Estado promulgante], en cualquier momento antes de que expire el plazo de vigencia de la inscripción registral. En el caso de una prórroga, el nuevo plazo comienza en el momento en que expire el plazo en curso; y

[c) Una notificación de modificación que no sea una notificación de modificación mencionada en el apartado b) de esta recomendación no prorroga el plazo de vigencia.]

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que en el comentario se explica que solamente una notificación de modificación que prorrogue el plazo de vigencia surte ese efecto. Otras notificaciones de modificación (por ejemplo, por las que se modifique la descripción de los bienes gravados) no prorrogan el plazo de vigencia. Habida cuenta de lo anterior, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar que el apartado c) en las tres variantes es superfluo puesto que afirma algo que es obvio y, en cualquier caso, se explica en el comentario. El Grupo de Trabajo tal vez desee también considerar si el apartado c) debería afirmar en su lugar (o añadir, si se retiene el actual apartado c)), en consonancia con la recomendación 11, que una notificación de modificación surte efecto en el momento en que se incorpora al fichero del registro para quedar a disposición de quienes deseen consultarla.]

Recomendación 14. Momento en el que podrá inscribirse una notificación

El reglamento debería disponer que una notificación [inicial o de modificación] pueda inscribirse antes o después de que se constituya la garantía real o de que se celebre el acuerdo de garantía pertinente.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de retener el texto entre corchetes en el título y el texto de esta recomendación, ya que es posible que una notificación inicial o de modificación esté inscrita previamente. Si las negociaciones no conducen a un acuerdo, en todo caso se deberá inscribir una notificación de cancelación.]

Recomendación 15. Suficiencia de una notificación única

El reglamento debería disponer que la inscripción de una sola notificación baste para dotar de eficacia frente a terceros a una o más garantías reales sobre el bien gravado descrito en la notificación constituidas por el otorgante a favor del mismo acreedor garantizado, tanto si están constituidas en el momento de la inscripción como si se constituyen ulteriormente, o si nacen de uno o más acuerdos de garantía concertados entre las mismas partes.

Recomendación 16. Indexación u otra forma de organizar la información del fichero del registro

El reglamento debería disponer que:

- a) El registro indexe u organice de otra manera la información consignada en una notificación inicial en el fichero del registro accesible al público de forma que se pueda consultar [toda persona pueda consultarla] por medio del identificador del otorgante o del número de inscripción asignado a la notificación inicial;
- b) El registro indexe u organice de otra manera la información consignada en una notificación de modificación en el fichero del registro accesible al público de forma que se pueda consultar [toda persona pueda consultarla] junto con la notificación inicial y toda notificación conexa; y
- c) El registro indexe u organice de otra manera la información consignada en una notificación de cancelación en los archivos del registro de modo que pueda ser recuperada [por el registro], de conformidad con la recomendación 21, junto con la notificación inicial y toda notificación conexa.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de retener un texto en consonancia con el texto entre corchetes para evitar que se dé a entender que una persona que realice una consulta puede tener acceso a la información archivada.]

Recomendación 17. Integridad del fichero del registro

El reglamento debería disponer que:

- a) Salvo lo previsto en las recomendaciones 19 y 20, el registro no modifique la información consignada en el fichero del registro ni retire información de él; y
- b) El registro proteja el fichero del registro contra pérdida o daños, y prevea mecanismos de copia de seguridad que permitan la reconstrucción del fichero del registro.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que el apartado b) se ha añadido para dar aplicación a una decisión del Grupo de Trabajo (A/CN.9/764, párr. 31). El Grupo de Trabajo tal vez desee también observar que en el comentario se explica que esta recomendación tiene por finalidad dar aplicación a la recomendación 55, apartado l) de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas y no se propone ocuparse de la responsabilidad, que es un asunto que se trata en la recomendación 56. En el comentario también se explica que el registro debería estar en condiciones de reconstruir información distinta de la consignada en las notificaciones inscritas (por ejemplo, cuentas, nombres de usuario, contraseñas, etc.).]

Recomendación 18. Copia de la notificación inscrita

El reglamento debería disponer que:

- a) El registro remita prontamente una copia de la notificación inscrita a cada acreedor garantizado a la dirección consignada en la notificación, indicando la fecha y hora en que adquirió validez y el número de inscripción; y

b) El acreedor garantizado envíe una copia de una notificación inicial a cada otorgante a la dirección consignada en la notificación y una copia de una notificación de modificación a cada otorgante a la dirección consignada en la notificación o a la dirección actual que conozca el acreedor garantizado en [un breve plazo, por ejemplo, 30 días, que especificará el Estado promulgante] después de que el acreedor asegurado haya recibido copia de la notificación inscrita.

Recomendación 19. Modificación de la información consignada en el fichero del registro accesible al público

El reglamento debería disponer que:

a) La información consignada en una notificación inscrita pueda ser enmendada por el acreedor garantizado mediante la inscripción de una notificación de modificación de conformidad con las recomendaciones 30, 31 o 33; y

b) La inscripción de una notificación de modificación no dé lugar a la retirada de información del fichero del registro accesible al público.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que en el comentario se explica que es necesario el consentimiento del otorgante para las siguientes modificaciones: añadir bienes gravados y aumentar el importe de la obligación garantizada o, cuando proceda, el importe máximo que pueda exigirse con arreglo a la garantía real. En el comentario también se explica que, al igual que en el caso de la inscripción de una notificación inicial, las pruebas que consten en el registro de la autorización del otorgante no son condición previa para la inscripción de una notificación de modificación, y la autorización del otorgante podrá concederse antes o después de la inscripción, ya sea en el acuerdo de garantía o en otro acuerdo que no conste en el registro. Si no se obtuvo autorización, el otorgante podrá solicitar la inscripción de una notificación de modificación mediante un procedimiento judicial o administrativo sumario (véase el proyecto de guía sobre el registro, recomendación 33). En el comentario también se analiza la validez de la inscripción de una notificación de modificación que no contaba con la autorización del acreedor asegurado, sino que era consecuencia de fraude u otra conducta dolosa de un tercero (véase A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, párrs. 28 a 37). El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si es suficiente analizar este asunto en el comentario o si debería abordarse en una recomendación que se incluiría en el proyecto de guía sobre el registro.]

Recomendación 20. Retirada de información del fichero del registro accesible al público

El reglamento debería disponer que la información consignada en una notificación inscrita se retire del fichero del registro accesible al público cuando expire su plazo de vigencia o cuando se inscriba una notificación de cancelación, de conformidad con las recomendaciones 32 o 33.

Recomendación 21. Archivo de la información retirada del fichero del registro accesible al público

El reglamento debería disponer que la información retirada del fichero del registro accesible al público de conformidad con la recomendación 20 se archive durante un plazo mínimo de [un plazo prolongado, como, por ejemplo, 20 años, que

deberá especificar el Estado promulgante] de manera que permita que la información se pueda recuperar de conformidad con la recomendación 16.

Recomendación 22. Idioma de la notificación

El reglamento debería disponer que:

- a) La información consignada en una notificación se exprese en [el idioma o idiomas que especifique el Estado promulgante]; y
- b) El registro especifique y dé a conocer públicamente el conjunto de caracteres que se habrá de utilizar.

IV. Inscripción de notificaciones iniciales

Recomendación 23. Información que ha de consignarse en una notificación inicial

El reglamento debería disponer que:

- a) La notificación inicial contenga la información siguiente en el espacio previsto:
 - i) El identificador del otorgante determinado de conformidad con las recomendaciones 24 a 26, la dirección del otorgante [y la demás información que especifique el Estado promulgante para ayudar a identificar de forma única al otorgante];
 - ii) El identificador del acreedor garantizado o su representante, determinado de conformidad con la recomendación 27, y la dirección del otorgante o su representante;
 - iii) Una descripción de los bienes gravados determinada de conformidad con las recomendaciones 28 y 29;
 - [iv) El plazo de vigencia de la inscripción determinado de conformidad con la recomendación 11¹; y
 - v) El importe monetario máximo por el que se podrá ejecutar la garantía real]²; y
- b) Si hay más de un otorgante o acreedor garantizado, la información prescrita deberá presentarse en el espacio previsto respecto de cada otorgante o acreedor garantizado por separado, en la misma notificación o en notificaciones diferentes.

Recomendación 24. Identificador del otorgante (persona física)

El reglamento debería disponer que, si el otorgante es una persona física:

- a) El identificador del otorgante sea el nombre del otorgante;

¹ Si el Estado promulgante ha optado por la variante B o C en la recomendación 11 (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 69).

² En caso de que así lo exija la ley sobre las operaciones garantizadas del Estado promulgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, apartado d)).

b) Cuando el nombre del otorgante consista en el apellido o apellidos y un nombre propio, el nombre del otorgante consista en el apellido o apellidos del otorgante y el nombre propio del otorgante, y cada componente del nombre se consigne en el espacio previsto para ese componente;

c) Cuando el nombre propio o el apellido o apellidos del otorgante consistan en más de una palabra, el nombre propio y el apellido o apellidos del otorgante consistan en esas palabras y se consignent en los espacios previstos para el nombre propio y los apellidos;

d) Cuando el nombre del otorgante consista en una sola palabra, el nombre del otorgante consista en esa palabra y se consigne en el espacio previsto para el apellido;

e) El nombre del otorgante se determine de la siguiente manera:

i) Si el otorgante nació en [el Estado promulgante insertará su nombre] y su nacimiento se registró en él en un organismo estatal encargado del registro de nacimientos, el nombre del otorgante sea el nombre que figure en la partida de nacimiento del otorgante o en el documento equivalente expedido por el organismo estatal;

ii) Si el otorgante nació en [el Estado promulgante insertará su nombre] pero su nacimiento no se registró en él, el nombre del otorgante sea el que figure en un pasaporte válido que le haya expedido [el Estado promulgante insertará su nombre];

iii) Si ninguno de los criterios indicados en los incisos i) o ii) del apartado e) de esta recomendación es aplicable, el nombre del otorgante sea el que figure en [el Estado promulgante deberá especificar el tipo de documento oficial, por ejemplo una tarjeta de identificación o un permiso de conducir, expedido al otorgante por el Estado promulgante, que este considere más apropiado para indicar el nombre que se ha de utilizar, y su orden de jerarquía];

iv) Si ninguno de los criterios indicados en los incisos i), ii) o iii) del apartado e) de esta recomendación es aplicable pero el otorgante es ciudadano de [el Estado promulgante insertará su nombre], el nombre del otorgante sea el que figure en el certificado que acredite su nacionalidad;

v) Si ninguno de los criterios indicados en los incisos i), ii), iii) o iv) del apartado e) de esta recomendación es aplicable, el nombre del otorgante sea el que figure en un pasaporte válido que le haya expedido el Estado del cual el otorgante sea ciudadano, y si el otorgante no posee un pasaporte válido el nombre del otorgante sea el nombre que figure en la partida de nacimiento o documento equivalente que le haya expedido el organismo estatal encargado del registro de nacimientos en el lugar en que nació el otorgante;

vi) En todo supuesto que no esté comprendido en los incisos i) a v) del apartado e) de esta recomendación, el nombre del otorgante sea el nombre que figure en dos de los documentos oficiales válidos siguientes [el Estado promulgante deberá especificar los documentos distintos de los indicados en el apartado iii) del párrafo e) de esta recomendación, como la tarjeta de la seguridad social, del seguro médico o de identificación fiscal, expedida al otorgante por el Estado promulgante, así como su orden de jerarquía].

Recomendación 25. Identificador del otorgante (persona jurídica)

El reglamento debería disponer que, si el otorgante es una persona jurídica, el identificador del otorgante sea el nombre del otorgante que se indique como su nombre en [el documento, la ley o el decreto especificado por el Estado promulgante] más reciente por el [la] que se constituya dicha persona jurídica.

[Recomendación 26. Identificador del otorgante (casos especiales)]

El reglamento debería disponer que:

a) Si los bienes gravados están sujetos a un procedimiento de insolvencia, el identificador del otorgante sea el nombre de la persona insolvente, determinado de conformidad con la recomendación 24 o 25, con la aclaración, en un espacio distinto, de que el otorgante se encuentra en procedimiento de insolvencia;

b) Si el otorgante es un consorcio o una empresa conjunta, el identificador del otorgante sea el nombre del consorcio o la empresa conjunta según conste en [el documento, la ley o el decreto especificado por el Estado promulgante] más reciente por el [la] que se constituya el consorcio o empresa determinado de conformidad con las recomendaciones 24 o 25;

c) [Si el otorgante es una sociedad fiduciaria o un patrimonio, el identificador del otorgante sea el nombre de la sociedad fiduciaria o el patrimonio determinado de conformidad con las recomendaciones 24 o 25, con la aclaración, en un espacio distinto, de que el otorgante es una sociedad fiduciaria o un patrimonio.]

d) Si el otorgante es una entidad distinta de las ya mencionadas en las reglas precedentes, el identificador del otorgante sea el nombre de la entidad que se indique en [el documento, la ley o el decreto especificado por el Estado promulgante] más reciente por el [la] que se constituya dicha entidad determinado de conformidad con las recomendaciones 24 o 25.]

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que en el comentario se explica que esta recomendación figura entre corchetes para indicar que su finalidad es exponer ejemplos de casos especiales para que los Estados promulgantes los seleccionen y adapten a sus propias leyes, ya que el régimen de estos casos puede ser diferente de un Estado a otro. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de hacer una referencia en su lugar en el apartado a) a un otorgante que esté sujeto a un procedimiento de insolvencia y el representante de la insolvencia constituya la garantía real. El texto actual sería aplicable incluso a las garantías reales constituidas por el otorgante antes del comienzo del procedimiento de insolvencia y, al parecer, exigiría una modificación de la notificación inscrita para indicar que el otorgante se encuentra en un procedimiento de insolvencia. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si el apartado d) es necesario o no. Hace una afirmación obvia ya que dispone que, en todos los demás casos, es aplicable la regla general mencionada en las recomendaciones 24 o 25.]

Recomendación 27. Identificador del acreedor garantizado

El reglamento debería disponer que:

- a) Si el acreedor garantizado o su representante es una persona física, el identificador sea el nombre del acreedor garantizado o su representante determinado de conformidad con la recomendación 24;
- b) Si el acreedor garantizado o su representante es una persona jurídica, el identificador sea el nombre del acreedor garantizado o su representante determinado de conformidad con la recomendación 25; y
- c) Si el acreedor garantizado o su representante es una persona de la clase indicada en la recomendación 26, el identificador sea el nombre de la persona determinado de conformidad con la recomendación 26.

Recomendación 28. Descripción de los bienes gravados

El reglamento debería disponer que:

- a) Los bienes gravados se describan en el espacio previsto de la notificación de manera que permita razonablemente identificarlos;
- b) Si la ley no dispone otra cosa, una descripción genérica que remita al conjunto de bienes de una determinada categoría de bienes muebles incluya todos los bienes actuales y futuros del otorgante pertenecientes a la categoría especificada; y
- c) Si la ley no dispone otra cosa, una descripción genérica que remita a los bienes muebles del otorgante incluya todos los bienes muebles actuales y futuros del otorgante.

Recomendación 29. Información incorrecta o insuficiente

El reglamento debería disponer que:

- a) La inscripción de una notificación inicial o una notificación de modificación que modifique el identificador del otorgante o agregue un otorgante solo surta efecto si facilita el identificador correcto del otorgante según lo dispuesto en las recomendaciones 24 a 26 o, de haberse indicado un identificador incorrecto, si es posible recuperar la notificación mediante una búsqueda en el fichero del registro accesible al público utilizando el identificador correcto del otorgante;
- b) Salvo lo previsto en el apartado a) de esta recomendación, una declaración incorrecta o insuficiente de la información que ha de suministrarse en una notificación no prive de validez a esa inscripción, si esa declaración incorrecta o insuficiente no induce a error grave al autor razonable de una consulta;
- c) Un identificador incorrecto de un otorgante en una notificación no prive de validez a su inscripción registral con respecto a otros otorgantes correctamente identificados en la notificación;
- d) Una descripción insuficiente de los bienes gravados en una notificación no prive de validez a su inscripción con respecto a otros bienes gravados suficientemente descritos en la notificación; y
- e) Una declaración incorrecta en una notificación con respecto al plazo de vigencia de la inscripción registral y el importe máximo por el que se puede ejecutar

la garantía real no prive de validez a la inscripción registral, excepto en la medida en que haya inducido a error grave a terceros que se hayan basado en la notificación inscrita.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si en el apartado a) de esta recomendación se debería hacer una referencia a una búsqueda por la lógica de búsqueda normal del registro. En teoría, siempre podría encontrarse el identificador de un otorgante si se utilizaran suficientes caracteres comodín. Otra posibilidad sería explicar este asunto en el comentario.]

V. Inscripción de notificaciones de modificación y cancelación

Recomendación 30. Información que deberá consignarse en una notificación de modificación

El reglamento debería disponer que:

- a) En una notificación de modificación se consigne, en el espacio previsto, la información siguiente:
 - i) El número de inscripción de la notificación inicial a que se refiera la modificación; y
 - ii) Si se ha de modificar información, la nueva información conforme a lo prescrito para introducir ese tipo de información en una notificación inicial de conformidad con la recomendación 23;
- b) Una notificación de modificación que divulgue una modificación del identificador del otorgante indique el nuevo identificador del otorgante de conformidad con las recomendaciones 24 a 26³;
- c) Una notificación de modificación que divulgue una transmisión de todos los bienes gravados indique el identificador y la dirección del beneficiario de la transmisión como otorgante de conformidad con las recomendaciones 24 a 26;
- d) Una notificación de modificación que divulgue una transmisión que afecte únicamente a una parte de los bienes gravados indique el identificador y la dirección del beneficiario de la transmisión como otorgante de conformidad con las recomendaciones 24 a 26 y describa la parte de los bienes gravados transmitidos de conformidad con la recomendación 28;
- e) Una notificación de modificación que divulgue una cesión de la obligación garantizada indique el identificador y la dirección del cesionario como acreedor garantizado de conformidad con la recomendación 27 y, en el caso de una cesión parcial, describa en el espacio previsto los bienes gravados a los que se refiere la cesión parcial; y

³ Este tipo de modificación es obligatorio en el sentido de que la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda que, si el acreedor garantizado no hace inscribir la modificación en un breve “plazo de gracia” especificado (por ejemplo, 15 días) después de que haya cambiado el identificador del otorgante, su garantía real no es oponible a compradores, a arrendadores, licenciarios y demás acreedores garantizados que adquieran derechos sobre el bien gravado después del cambio del identificador del otorgante y antes de que se inscriba dicha modificación (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 61).

f) Una notificación de modificación pueda referirse a uno o varios elementos de información en una notificación.

Recomendación 31. Modificación global de la información relativa a un acreedor garantizado consignada en múltiples notificaciones

Variante A

El reglamento debería disponer que un acreedor garantizado mencionado en múltiples notificaciones inscritas pueda modificar la información relativa al acreedor garantizado en todas esas notificaciones mediante una única modificación global.

Variante B

El reglamento debería disponer que un acreedor garantizado mencionado en múltiples notificaciones inscritas pueda solicitar al registro que modifique la información relativa al acreedor garantizado en todas esas notificaciones mediante una modificación global única.

Recomendación 32. Información que deberá contener una notificación de cancelación

El reglamento debería disponer que las notificaciones de cancelación contengan en el espacio previsto el número de inscripción de la notificación a que se refiere la cancelación.

Recomendación 33. Modificación o cancelación obligatorias

El reglamento debería disponer que:

a) El acreedor asegurado esté obligado a inscribir una notificación de modificación o cancelación, según proceda, si:

i) La inscripción registral de una notificación inicial o de modificación no ha sido autorizada por el otorgante en absoluto o en la medida descrita en la notificación;

ii) La inscripción registral de una notificación inicial o de modificación ha sido autorizada por el otorgante pero la autorización ha sido retirada o no se ha concertado ningún acuerdo de garantía;

iii) El acuerdo de garantía ha sido revisado de manera que la información consignada en la notificación resulte incorrecta o insuficiente; o

iv) La garantía real a que se refiere la notificación se ha extinguido por pago u otro cumplimiento de la obligación garantizada, o de otra forma, y el acreedor garantizado no tenga ya obligación de conceder crédito;

b) En el caso de los incisos ii) a iv) del apartado a) de esta recomendación el acreedor garantizado pueda cobrar los honorarios convenidos con el otorgante;

c) A más tardar [un plazo breve de tiempo, por ejemplo, 15 días, que especificará el Estado promulgante] tras haber recibido una solicitud por escrito del otorgante, el acreedor garantizado esté obligado a cumplir con su obligación de conformidad con el apartado a) de esta recomendación;

d) No obstante lo dispuesto en el apartado b) de esta recomendación, el acreedor garantizado no pueda cobrar ni aceptar ningún honorario u otra suma de dinero si cumple con una solicitud escrita del otorgante de conformidad con el apartado c) de esta recomendación;

e) Si el acreedor garantizado no cumple en el plazo previsto en el apartado c) de esta recomendación, el otorgante tenga derecho a solicitar una modificación o cancelación, según proceda, por conducto de un procedimiento judicial o administrativo sumario;

f) El otorgante tenga derecho a pedir una modificación o cancelación, según proceda, por conducto de un procedimiento judicial o administrativo sumario incluso antes de que expire el plazo mencionado en el apartado c) de esta recomendación, siempre que existan mecanismos adecuados para amparar al acreedor garantizado; y

g) La notificación de modificación o cancelación de conformidad con esta recomendación sea inscrita por

Variante A

el registro, sin demora, al recibo de la notificación adjuntando la correspondiente orden judicial o administrativa.

Variante B

un funcionario judicial o administrativo, sin demora, cuando se expida la correspondiente orden judicial o administrativa con una copia de la misma adjunta.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que en el comentario se explica que la garantía real se podrá extinguir de distintas formas, incluido el cumplimiento, la liquidación, la ejecución, la compensación, la resolución del acuerdo de garantía en la insolvencia o la resolución del acuerdo de garantía por otra razón (por ejemplo, ilegalidad).]

VI. Consultas

Recomendación 34. Criterio de consulta

El reglamento debería disponer que el criterio aplicable a la realización de una consulta del fichero del registro accesible al público sea:

- a) El identificador del otorgante; o
- b) El número de inscripción registral.

Recomendación 35. Resultado de la consulta

El reglamento debería disponer que:

- a) En el resultado de la consulta que suministre el registro se indiquen la fecha y hora en que se efectuó la consulta y se consigne toda la información de cada notificación inscrita que coincida con el criterio de consulta especificado o se indique que ninguna notificación inscrita coincidió con el criterio de consulta;

b) El resultado de una consulta refleje información consignada en el fichero del registro accesible al público que coincida exactamente con el criterio de búsqueda excepto [en los casos en que un resultado de búsqueda pueda reflejar información consignada en el fichero del registro accesible al público que coincida aproximadamente con el criterio de búsqueda y las reglas (lógica de búsqueda) que utilice el registro para determinar lo que constituye una coincidencia aproximada, que especificará el Estado promulgante];

c) A solicitud de la persona que realice la consulta, el registro expida un certificado oficial de consulta en el que se indique el resultado de la búsqueda.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que en el comentario se exponen ejemplos de reglas para determinar lo que constituye una coincidencia aproximada.]

VII. Tasas

Recomendación 36. Tasas por concepto de servicios del registro

El reglamento debería disponer que:

Variante A

a) [A reserva de lo dispuesto en el apartado b) de esta recomendación,] se paguen las siguientes tasas por concepto de servicios de registro:

i) Inscripciones registrales:

- a. En papel [...];
- b. Electrónicas [...];

ii) Consultas:

- a. En papel [...];
- b. Electrónicas [...];

iii) Certificados:

- a. En papel [...];
- b. Electrónicos [...];

b) El registro pueda concertar un acuerdo con toda persona que cumpla todas las condiciones del registro y crear una cuenta de usuario del registro que facilite el pago de las tasas.

Variante B

La [autoridad administrativa que especifique el Estado promulgante] pueda determinar las tasas y métodos de pago a efectos del presente reglamento mediante decreto.

Variante C

Los servicios [del registro] [de consulta] [de consulta electrónica] sean gratuitos.

(A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.6) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23º período de sesiones

ADICIÓN

Anexo II. Ejemplos de formularios de registro

Nota de la Secretaría

Adición

El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar los ejemplos de formularios de registro que figuran en la presente nota. Los ejemplos se presentan como anexo II del proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, a continuación del anexo I, que versa sobre terminología y recomendaciones. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si habría que preparar otros ejemplos de formularios, tales como listas para asentar información suplementaria.

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES

EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN INICIAL

(FORMULARIO A)

EL SOLICITANTE DE LA INSCRIPCIÓN SERÁ RESPONSABLE DE VELAR POR QUE SE SUMINISTRE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE CONSIGNE EN EL ESPACIO PREVISTO DE LA NOTIFICACIÓN EN FORMA LEGIBLE.

[Momento en que adquiere eficacia la inscripción. (dd) (mm) (aaaa) (hora)*

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN]¹

A. INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGANTE

1. PERSONA FÍSICA

...../...../...../
Apellido(s) Primer nombre Segundo nombre

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE (OPCIONAL)

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

* En cifras.

¹ Lo asignará el registro. Si se trata de un registro electrónico, la información se generará automáticamente.

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE (OPCIONAL)

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)3. SÍRVASE INDICAR SI EL OTORGANTE ES²

... una persona insolvente

... un consorcio o una empresa conjunta

... una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre se ha dado

[... una entidad diferente de las arriba mencionadas]

4. OTORGANTE ADICIONAL (si corresponde)

a) PERSONA FÍSICA

NOMBRE/...../...../

Apellido(s)

Primer nombre

Segundo nombre

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE (OPCIONAL)

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

b) PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE (OPCIONAL)

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

c) INDIQUE SI EL OTORGANTE ES

... una persona insolvente

... un consorcio o una empresa conjunta

... una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre se ha dado

[... una entidad diferente de las arriba mencionadas]

² Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que esta parte refleja los casos especiales previstos en la recomendación 26.

B. INFORMACIÓN SOBRE EL ACREEDOR GARANTIZADO

1. PERSONA FÍSICA

...../...../...../
 Apellido(s) Primer nombre Segundo nombre

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
 U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
 U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

3. ACREEDOR GARANTIZADO ADICIONAL (si corresponde)

a) PERSONA FÍSICA

NOMBRE
/...../...../
 Apellido(s) Primer nombre Segundo nombre

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
 U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

b) PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
 U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

C. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GRAVADOS

1. GENERAL

2. NÚMERO DE SERIE (OPCIONAL)

[D. PLAZO DE VALIDEZ DE LA INSCRIPCIÓN (dd) (mm) (aaaa)]³

[E. CUANTÍA MÁXIMA POR LA QUE ES EJECUTABLE LA GARANTÍA REAL]⁴

F. INFORMACIÓN ADICIONAL] (OPCIONAL)

³ Si el Estado promulgante ha elegido las variantes B o C de la recomendación 13 (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 69).

⁴ Si así se exige en la ley de operaciones garantizadas del Estado promulgante (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 57, apartado d)).

G. INDIQUE SI LA INSCRIPCIÓN ES TRANSITORIA, EL CRITERIO DE ÍNDEXACIÓN DEL REGISTRO ANTERIOR, Y LA FECHA Y HORA EN QUE LA INSCRIPCIÓN ADQUIERE EFICACIA

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que se ha añadido la parte G para incluir las inscripciones transitorias. La finalidad de esa parte es mantener la continuidad de la eficacia frente terceros desde la fecha anterior de inscripción, tal como se contempla en las disposiciones transitorias por las que se aplica el nuevo régimen a las garantías reales existentes (véase la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, recomendación 231). Manteniendo los datos antiguos se puede verificar la existencia y la fecha de una inscripción realizada con arreglo al régimen anterior para el caso de que surja una controversia. Indicando que se trata de una inscripción transitoria se garantiza que todo aquel que realice una búsqueda sepa que la fecha de la eficacia frente a terceros es anterior en el tiempo. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la posibilidad de que quizá no valga la pena entrar en más detalle acerca de la migración de los datos, teniendo en cuenta que posiblemente los costos y el esfuerzo relativos a esa migración no valgan la pena, dado que los sistemas antiguos suelen ser sistemas de inscripción documental y el registro podría incurrir en responsabilidades si no extrae la información adecuada de los ficheros antiguos al consignarla en el fichero del nuevo registro. En una inscripción transitoria, es el solicitante de la inscripción quien debe hacer la indicación, lo que constituye un enfoque más eficiente, y los terceros pueden obtener la verificación de los archivos antiguos en caso de que surja una controversia, cosa que rara vez ocurre. Asimismo, cabe observar que tal vez ya no sea posible realizar una consulta pública de los archivos de registro antiguos, sino que solo pueda realizarla el personal del registro previa solicitud, cosa que también ocurre en pocas ocasiones.]

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES**EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN****(FORMULARIO B)**

EL SOLICITANTE DE LA INSCRIPCIÓN SERÁ RESPONSABLE DE VELAR POR QUE SE SUMINISTRE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE CONSIGNE EN EL ESPACIO PREVISTO DE LA NOTIFICACIÓN EN FORMA LEGIBLE.

ELIJA UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

- Añadir o suprimir un otorgante o modificar/editar la información sobre el otorgante
- Añadir o suprimir un acreedor garantizado o modificar/editar la información sobre el acreedor garantizado
- Añadir o suprimir un bien gravado o modificar/editar la descripción de los bienes gravados (también para añadir una descripción de bienes que sean producto de los bienes gravados originales)
- [Prorrogar el plazo de vigencia de la inscripción (cuando el Estado promulgante haya establecido un plazo de vigencia universal de la inscripción o un plazo máximo de la inscripción inicial)]

- [Prorrogar o reducir el plazo de vigencia de la inscripción (cuando el Estado promulgante permita a los acreedores garantizados especificar el plazo de vigencia de la inscripción)]
- [Modificar la cuantía máxima por la que es ejecutable la garantía real (cuando el Estado promulgante lo permita)]
- Modificar la información sobre un acreedor garantizado en todas las notificaciones con una única modificación global

[Momento en que adquiere eficacia la inscripción. (dd) (mm) (aaaa) (hora)*]⁵

A. NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN INICIAL

B. AÑADIR UN OTORGANTE

1. PERSONA FÍSICA

...../...../.....
 Apellido(s) Primer nombre Segundo nombre

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE (OPCIONAL)

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
 U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE (OPCIONAL)

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
 U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

3. SÍRVASE INDICAR SI EL OTORGANTE ES

... una persona insolvente

... un consorcio o una empresa conjunta

... una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre se ha dado

[... una entidad diferente de las arriba mencionadas]

* En cifras.

⁵ Lo asignará el registro. Si se trata de un registro electrónico, la información se generará automáticamente.

C. SUPRIMIR UN OTORGANTE**1. PERSONA FÍSICA**

NOMBRE:

...../...../.....
Apellido(s) Primer nombre Segundo nombre

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

3. SÍRVASE INDICAR SI EL OTORGANTE ES

... una persona insolvente

... un consorcio o una empresa conjunta

... una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre se ha dado

[... una entidad diferente de las arriba mencionadas]

D. MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGANTE**1. PERSONA FÍSICA**

NOMBRE:

...../...../.....
Apellido(s) Primer nombre Segundo nombre

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE (OPCIONAL)

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)**2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD**

NOMBRE

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE (OPCIONAL)

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)**3. SÍRVASE INDICAR SI EL OTORGANTE ES**

... una persona insolvente

... un consorcio o una empresa conjunta

... una sociedad fiduciaria o un patrimonio cuyo nombre se ha dado

[... una entidad diferente de las arriba mencionadas]

E. AÑADIR UN ACREEDOR GARANTIZADO

1. PERSONA FÍSICA

...../...../.....
 Apellido(s) Primer nombre Segundo nombre
 DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
 U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE
 DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
 U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

F. SUPRIMIR UN ACREEDOR GARANTIZADO

1. PERSONA FÍSICA

...../...../.....
 Apellido(s) Primer nombre Segundo nombre

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

G. MODIFICAR LA INFORMACIÓN SOBRE UN ACREEDOR GARANTIZADO

1. PERSONA FÍSICA

...../...../.....
 Apellido(s) Primer nombre Segundo nombre

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
 U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE
 DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
 U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

H. ADICIONES, SUPRESIONES O MODIFICACIONES EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES GRAVADOS

.....

[I. PRORROGAR EL PLAZO DE VALIDEZ DE LA INSCRIPCIÓN (cuando en la ley del Estado promulgante se haya fijado un plazo determinado) *]

[J. PRORROGAR O REDUCIR EL PLAZO DE VALIDEZ DE LA INSCRIPCIÓN (cuando el Estado promulgante permita a los acreedores garantizados especificar el plazo de vigencia de la inscripción)

_____ (dd) _____ (mm) _____ (aaaa)*]

[K. MODIFICAR LA CUANTÍA MÁXIMA POR LA QUE SE PUEDE EJECUTAR LA GARANTÍA REAL]*

**REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES
EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE MODIFICACIÓN
(FORMULARIO C)**

EL SOLICITANTE DE LA INSCRIPCIÓN SERÁ RESPONSABLE DE VELAR POR QUE SE SUMINISTRE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE CONSIGNE EN EL ESPACIO PREVISTO DE LA NOTIFICACIÓN EN FORMA LEGIBLE.

[Momento en que adquiere eficacia la inscripción..... (dd) (mm) (aaaa) (hora)*]⁶

A. NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN INICIAL

B. INFORMACIÓN QUE SE HA DE AÑADIR O SUPRIMIR CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR UNA AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA

.....
.....
.....

C. PERSONA QUE PRESENTA UNA NOTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN CON ARREGLO A UNA ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA

NOMBRE DE LA PERSONA

CARGO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

D. ADJUNTE LA ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA

* En cifras.

⁶ Lo asignará el registro. Si se trata de un registro electrónico, la información se generará automáticamente.

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES
EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN
(FORMULARIO D)

EL SOLICITANTE DE LA INSCRIPCIÓN SERÁ RESPONSABLE DE VELAR POR QUE SE SUMINISTRE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE CONSIGNE EN EL ESPACIO PREVISTO DE LA NOTIFICACIÓN EN FORMA LEGIBLE.

[Momento en que adquiere eficacia la inscripción..... (dd) (mm) (aaaa) (hora)*]⁷

A. NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN INICIAL

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES
EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE CANCELACIÓN
(FORMULARIO E)

EL SOLICITANTE DE LA INSCRIPCIÓN SERÁ RESPONSABLE DE VELAR POR QUE SE SUMINISTRE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE CONSIGNE EN EL ESPACIO PREVISTO DE LA NOTIFICACIÓN EN FORMA LEGIBLE.

[Momento en que adquiere eficacia la inscripción..... (dd) (mm) (aaaa) (hora)*]⁸

A. NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN INICIAL

B. PERSONA QUE PRESENTA UNA NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN CON ARREGLO A UNA ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA

NOMBRE DE LA PERSONA

CARGO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN (DIRECCIÓN POSTAL, APARTADO POSTAL, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA U OTRO TIPO DE DIRECCIÓN)

C. ADJUNTE LA ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA

* En cifras.

⁷ Lo asignará el registro. Si se trata de un registro electrónico, la información se generará automáticamente.

* En cifras.

⁸ Lo asignará el registro. Si se trata de un registro electrónico, la información se generará automáticamente.

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES
EJEMPLO DE SOLICITUD DE CONSULTA
(FORMULARIO F)

EL AUTOR DE LA CONSULTA SERÁ RESPONSABLE DE VELAR POR QUE SE SUMINISTRE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE CONSIGNE EN EL ESPACIO PREVISTO DE LA NOTIFICACIÓN EN FORMA LEGIBLE.

[Momento en que adquiere eficacia la inscripción..... (dd) (mm) (aaaa) (hora)*]⁹

A. INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGANTE

1. PERSONA FÍSICA

...../...../...../
 Apellido(s) Primer nombre Segundo nombre

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE (OPCIONAL)

2. PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE (OPCIONAL)

3. OTORGANTE ADICIONAL (si corresponde)

a) PERSONA FÍSICA

NOMBRE:/...../...../
 Apellido(s) Primer nombre Segundo nombre

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE (OPCIONAL)

b) PERSONA JURÍDICA U OTRA ENTIDAD

NOMBRE

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL OTORGANTE (OPCIONAL)

B. NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN INICIAL

* En cifras.

⁹ Lo asignará el registro. Si se trata de un registro electrónico, la información se generará automáticamente.

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES**EJEMPLO DE RESULTADO DE UNA CONSULTA¹⁰****(FORMULARIO G)**

A. LA CONSULTA SE REALIZÓ EL (dd)/ (mm)/ (aaaa)*.

B. SE ENCONTRARON LAS SIGUIENTES NOTIFICACIONES:

.....

C. NO SE ENCONTRARON NOTIFICACIONES.

REGISTRO DE GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES**EJEMPLO DE RECHAZO DE UNA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O DE CONSULTA****(FORMULARIO H)**

[..... (dd) (mm) (aaaa) (hora)]¹¹

A. SE RECHAZA LA INSCRIPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PORQUE:

1. En caso de una notificación inicial, no se ha consignado en forma legible en el espacio previsto:
 - a) El identificador y la dirección del otorgante,
 - b) El identificador y la dirección del acreedor garantizado o de su representante,
 - c) La descripción de los bienes gravados,
 - d) [El plazo de vigencia de la inscripción],
 - e) [El importe monetario máximo por el que se podrá ejecutar la garantía real].
2. En caso de una notificación de modificación, no se ha consignado en forma legible en el espacio previsto:
 - a) El número de inscripción de la notificación inscrita a la que se refiere la modificación,
 - b) Si se ha de agregar información, la información que habrá de agregarse,
 - c) Si se ha de modificar información, la información que habrá de modificarse.

¹⁰ Lo asignará el registro. Si se trata de un registro electrónico, el certificado de consulta será una versión imprimible del resultado de la búsqueda.

¹¹ Lo asignará el registro. Si se trata de un registro electrónico, la información se generará automáticamente.

3. En caso de una notificación de cancelación, no se ha consignado en forma legible en el espacio previsto el número de inscripción.

B. LA SOLICITUD DE CONSULTA SE HA RECHAZADO PORQUE NO SE HA CONSIGNADO EN FORMA LEGIBLE EN EL ESPACIO PREVISTO:

1. El identificador del otorgante o
2. El número de inscripción.

**E. Nota de la Secretaría sobre el proyecto de ley modelo sobre las
operaciones garantizadas, presentada al Grupo de Trabajo
sobre Garantías Reales en su 23º período de sesiones**

(A/CN.9/WG.VI/WP.55 y Add.1 a Add.4)

[Original: inglés]

Índice

Preámbulo	
Capítulo I. Disposiciones generales	
Artículo 1. Ámbito de aplicación	
Artículo 2. Definiciones	
Artículo 3. Autonomía contractual	
Artículo 4. Comunicaciones electrónicas	

Preámbulo

La finalidad de la presente Ley es:

- a) Fomentar la concesión de crédito asequible incrementando la oferta de crédito garantizado;
- b) Permitir que los otorgantes se valgan del pleno valor inherente de sus bienes para respaldar el crédito;
- c) Facilitar a los acreedores garantizados la obtención de garantías reales de manera sencilla y eficiente;
- d) Tratar por igual a las diversas fuentes de financiación y a las distintas formas de operaciones garantizadas;
- e) Reconocer la validez de las garantías reales sin desplazamiento constituidas sobre todos los tipos de bienes;
- f) Incrementar la certeza y la transparencia previendo la inscripción registral de una notificación de una garantía real en un registro general de las garantías reales;
- g) Establecer normas de prelación claras y previsibles;
- h) Facilitar la ejecución eficiente de las garantías de los acreedores;
- i) Conceder a las partes la máxima flexibilidad posible para negociar las cláusulas de su acuerdo de garantía;
- j) Compaginar los intereses de todas las personas afectadas; y
- k) Armonizar los regímenes de las operaciones garantizadas, inclusive las reglas sobre conflictos de leyes relativas a las operaciones garantizadas.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si en el comentario del proyecto de Ley Modelo se debería aclarar, de conformidad con el mandato que la Comisión encomendó al Grupo de Trabajo (véase A/67/17, párr. 105) que se tiene la intención de que el proyecto de Ley Modelo sea una ley modelo sencilla, breve y concisa para ayudar a los Estados a incorporar al derecho interno las recomendaciones generales de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (la “Guía sobre las Operaciones Garantizadas”), en consonancia con la Guía sobre las Operaciones Garantizadas y sin sustituirla.]

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Variante A

1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 3 de este artículo, la presente Ley es aplicable a todos los derechos sobre bienes muebles constituidos mediante un acuerdo que garantice el pago u otro tipo de cumplimiento de una obligación, independientemente de la forma que revista la operación o de la terminología empleada por las partes, del tipo de bien mueble, de la posición reconocida al otorgante o al acreedor garantizado o de la naturaleza de la obligación garantizada, inclusión hecha de:

a) Las garantías reales sobre todos los tipos de bienes muebles, corporales o inmateriales, presentes o futuros, inclusive las existencias, los bienes de equipo y otros bienes corporales, los créditos por cobrar contractuales y extracontractuales, y las obligaciones contractuales no monetarias;

b) Las garantías reales constituidas o adquiridas por toda persona jurídica o física, inclusive los consumidores, pero sin que ello afecte a los derechos previstos en la legislación de protección del consumidor;

c) Las garantías reales que respalden todo tipo de obligaciones presentes o futuras, determinadas o por determinar, inclusive las de monto fluctuante y las que estén descritas en términos genéricos; y

d) Todo derecho real nacido de un contrato por el que se garantice el pago u otra forma de cumplimiento de una obligación, inclusive las transmisiones de la titularidad sobre bienes corporales con fines de garantía o las cesiones de créditos por cobrar con idénticos fines, las diversas formas de venta con retención de la titularidad y los arrendamientos financieros.

2. La presente Ley también es aplicable a:

a) Las garantías reales constituidas sobre el producto de bienes gravados; y

b) A reserva de la excepción prevista en el artículo 100, a las cesiones puras y simples de créditos por cobrar, aunque tales transmisiones no garanticen el pago u otro tipo de cumplimiento de una obligación.

3. No obstante lo previsto en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, esta Ley no es aplicable a:

- a) Los derechos al cobro de fondos depositados en una cuenta bancaria;
- b) Los derechos al cobro del producto de una promesa independiente;
- c) Los títulos negociables y los documentos negociables;
- d) Aeronaves, material rodante ferroviario, objetos espaciales y buques, ni a otras categorías de bienes de equipo móvil, en la medida en que esos bienes se rijan por alguna norma de derecho interno o por algún acuerdo internacional en el que sea parte el Estado promulgante de una ley basada en estos artículos (en lo sucesivo, denominado “el Estado” o “este Estado”) y en que las cuestiones abordadas en la presente Ley sean reglamentadas por dicha norma nacional o dicho acuerdo internacional;
- e) Los derechos de propiedad intelectual;
- f) Los valores bursátiles;
- g) Los derechos de cobro que nazcan o dimanen de contratos financieros que se rijan por acuerdos de compensación global, salvo un crédito por cobrar adeudado una vez concluidas todas las operaciones pendientes;
- h) Los derechos de cobro que nazcan o dimanen de operaciones con divisas;
- i) Con la excepción de los artículos 11, 15, 27, 32, 55, 98, 99, 109 y 120, los bienes inmuebles;
- j) El producto de un bien de una categoría excluida aunque sea producto de una categoría de bien a que sea aplicable la presente Ley, salvo en la medida en que sea aplicable otra ley; y
- k) [Otra(s) excepción(es) que añadirá el Estado promulgante].

Variante B

1. La presente ley es aplicable a las garantías reales sobre bienes, existencias, bienes de equipo y créditos por cobrar.

2. Las garantías reales a las que es aplicable la presente Ley podrán:

- a) Ser constituidas o adquiridas por toda persona jurídica y física, inclusive los consumidores, pero sin que ello afecte a los derechos previstos en la legislación de protección del consumidor; y
- b) Garantizar todo tipo de obligaciones presentes o futuras, determinadas o por determinar, inclusive las de monto fluctuante y las que estén descritas en términos genéricos.

3. La presente Ley también es aplicable a:

- a) Las garantías reales constituidas sobre el producto de bienes gravados;
- b) A reserva de la excepción prevista en el artículo 100, las cesiones puras y simples de créditos por cobrar, aunque tales cesiones no garanticen el pago u otro tipo de cumplimiento de una obligación; y

c) Todo derecho real nacido de un contrato por el que se garantice el pago u otra forma de cumplimiento de una obligación, inclusive las transmisiones de titularidad sobre bienes corporales con fines de garantía, las cesiones de créditos por cobrar con idénticos fines, las diversas formas de venta con retención de la titularidad y los arrendamientos financieros.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que la variante A se basa en la recomendación 2 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, debidamente revisada para excluir determinados tipos de bienes que están sujetos a las recomendaciones específicamente relacionadas con los bienes de conformidad con la decisión de la Comisión de emprender “la preparación de una ley modelo sobre las operaciones garantizadas que fuera sencilla, breve y concisa y que estuviese basada en las recomendaciones generales de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas” (véase A/67/17, párr. 105). Sin embargo, se incluyen los créditos por cobrar en cumplimiento de la decisión de la Comisión de que el proyecto de Ley Modelo estuviese “en consonancia con todos los textos preparados por la CNUDMI sobre el tema de las operaciones garantizadas” (A/67/17, párr. 105), inclusión hecha de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional (en lo sucesivo, la “Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos”). Habida cuenta de la dependencia mutua de los créditos por cobrar y los bienes, equipo y existencias, la exclusión de los créditos por cobrar daría lugar a la aplicación de leyes diferentes en el caso, por ejemplo, en que se vendieran existencias y se transformaran en créditos por cobrar que, a su vez, se utilizaran para comprar nuevas existencias. Ese enfoque podría tener un efecto negativo en la disponibilidad y el costo del crédito. A ese respecto, el Grupo de Trabajo tal vez desee observar que, si bien es cierto que la Convención es aplicable únicamente a los créditos por cobrar contractuales, en consonancia con las recomendaciones de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, el proyecto de Ley Modelo es aplicable igualmente a los créditos por cobrar extracontractuales.]

Además, el Grupo de Trabajo tal vez desee observar que, a fin de velar por que el proyecto de Ley Modelo no sea incompatible con el enfoque funcional, integrado y unitario de las operaciones garantizadas que se recomienda en la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, (véase el capítulo I, párrs. 101 a 112), en el comentario se debería explicar que: a) el proyecto de Ley Modelo es una forma económica de dar aplicación a las recomendaciones de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas acerca de los bienes comerciales básicos (bienes, bienes de equipo, existencias y créditos por cobrar), sin sustituir a la Guía sobre las Operaciones Garantizadas; y b) se alienta a los Estados a que adopten el enfoque funcional, integrado y unitario y, en consecuencia, apliquen todas las recomendaciones de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, inclusión hecha de las relacionadas específicamente con los bienes, al menos en la medida en que no cuenten con normas o normas modernas sobre las garantías reales sobre estos tipos de bienes.

Asimismo, el Grupo de Trabajo tal vez desee observar que la variante B se propone reflejar la misma política incorporada en la variante A de una forma más económica, es decir, refiriéndose directamente a bienes, bienes de equipo, existencias y créditos por cobrar. Con ese enfoque, el párrafo 3 y las definiciones pertinentes de los términos que en él se incluyen resultarían innecesarios.

Si el Grupo de Trabajo decide mantener la variante A, tal vez desee considerar si el apartado j) del párrafo 3 es procedente. Por ejemplo, si se vende propiedad intelectual por dinero en efectivo y el vendedor utiliza ese dinero en efectivo para comprar existencias, las existencias serían producto de la propiedad intelectual. En contra de lo que dispone el apartado j) del párrafo 3, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar que el proyecto de Ley Modelo debería ser aplicable a las existencias aunque otro régimen jurídico abarcara las existencias (al menos, en el caso en que el otro régimen fuera insuficiente, es decir, por ejemplo, no exigiera la inscripción de una notificación en el registro general de garantías reales). Además, como cuestión práctica, el apartado j) del párrafo 3 requeriría que un acreedor garantizado que concediera financiación garantizada por una garantía real sobre un bien gravado a un deudor llevara a cabo una investigación acerca de si el bien gravado es producto de bienes que no estarían sujetos al proyecto de Ley Modelo. Una norma de esa índole podría aumentar el costo o reducir la oferta de crédito.]

Artículo 2. Definiciones

A los efectos de la presente Ley:

a) Por “acreedor garantizado financiador de adquisiciones” se entenderá todo acreedor garantizado que disponga de una garantía real para financiar adquisiciones. En el marco del enfoque unitario, el concepto engloba al vendedor con retención de la titularidad o al arrendador financiero;

b) Por “garantía real del pago de una adquisición” se entenderá una garantía real constituida sobre bienes, bienes de equipo o existencias, que respalde la obligación de pagar cualquier parte no abonada del precio de compra de los bienes o una obligación contraída o un crédito otorgado para facilitar al otorgante la adquisición de tales bienes;

c) Por “cesionario” se entenderá la persona a quien se ceda un crédito por cobrar;

d) Por “cesión” se entenderá la constitución de una garantía real sobre un crédito por cobrar que respalda su pago o el cumplimiento de otra obligación, inclusive una cesión pura y simple de un crédito por cobrar, sin reclasificarla como operación garantizada;

e) Por “cedente” se entenderá la persona que ceda un crédito por cobrar;

f) Por “bien incorporado a otro bien mueble” se entenderá todo bien corporal que esté adherido o incorporado a otro bien corporal, pero que no haya perdido su identidad propia;

g) Por “bien incorporado a un bien inmueble” se entenderá todo bien corporal que esté tan firmemente adherido o incorporado a un bien inmueble que, a pesar de no haber perdido su identidad propia, se le considera como si fuera un bien inmueble conforme a la legislación del Estado en que se encuentre el bien inmueble;

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que se ha suprimido la expresión “cuenta bancaria” (y otros tipos de bienes de los que no se ocupa el proyecto de Ley Modelo) y otras expresiones como “tribunal de la insolvencia”, “masa de la insolvencia” y “procedimiento de insolvencia”, ya

que normalmente estarían definidas en otra ley del Estado promulgante, y no en su ley sobre operaciones garantizadas.]

h) Por “reclamante concurrente” se entenderá el acreedor de un otorgante que compita con otro acreedor del otorgante que tenga una garantía real sobre un bien gravado del otorgante, concepto que englobará:

i) A otro acreedor que esté respaldado por una garantía real sobre el mismo bien gravado (ya sea en calidad de bien gravado originario o de producto);

ii) Al vendedor o al arrendador financiero del mismo bien gravado que haya conservado la titularidad de este;

iii) A otro acreedor del otorgante que tenga un derecho sobre el mismo bien gravado;

iv) Al representante de la insolvencia en el procedimiento de insolvencia con respecto al otorgante; o

v) A todo comprador o beneficiario de una transmisión (inclusive un arrendatario o un licenciataria) del bien gravado;

i) Por “bienes de consumo” se entenderá todo bien que un otorgante utilice o que se proponga utilizar para fines personales, familiares o domésticos;

j) Por “deudor” se entenderá la persona a la que corresponda cumplir una obligación garantizada, lo cual incluye a los obligados secundarios, como, por ejemplo, al garante de una obligación garantizada. El deudor no es necesariamente la persona que constituye la garantía real;

k) Por “deudor del crédito por cobrar” se entenderá toda persona a quien corresponda pagar un crédito por cobrar e incluirá a un garante, u otra persona que sea subsidiariamente responsable del crédito por cobrar;

l) Por “bien gravado” se entenderá todo bien mueble corporal o inmaterial sobre el que se haya constituido una garantía real. Este concepto engloba también un crédito por cobrar que haya sido objeto de una transmisión pura y simple;

m) Por “bienes de equipo” se entenderá todo bien corporal que una persona haya de utilizar en la explotación de su empresa;

n) Por “derecho al arrendamiento financiero” se entenderá el derecho de un arrendador sobre un bien corporal (que no sea un título negociable ni un documento negociable) que sea objeto de un contrato de arrendamiento, al final de cuyo plazo:

i) El arrendatario pasa automáticamente a ser el propietario del bien corporal que sea objeto del arrendamiento;

ii) El arrendatario podrá adquirir la propiedad del bien mediante el pago de un precio no superior al precio nominal; o

iii) El bien solo tiene un valor residual nominal.

El concepto incluye también un acuerdo de arrendamiento con opción de compra, aun cuando no sea denominado “arrendamiento”, siempre y cuando cumpla los requisitos de los incisos i), ii) o iii);

o) Por “otorgante” se entenderá toda persona que constituya una garantía real con objeto de respaldar su propia obligación o la de otra persona, incluido el comprador con retención de la titularidad, el arrendatario financiero o un cedente en una cesión pura y simple de un crédito por cobrar;

p) Por “representante de la insolvencia” se entenderá toda persona o todo órgano, inclusive las personas u órganos nombrados con carácter provisional, que, en un procedimiento de insolvencia, estén facultados para administrar la reorganización o la liquidación de la masa de la insolvencia;

q) Por “bien inmaterial” se entenderá todo tipo de bienes muebles que no sean corporales, así como los derechos inmateriales, los créditos por cobrar y los derechos al cumplimiento de obligaciones que no sean créditos por cobrar;

r) Por “existencias” se entenderán los bienes corporales almacenados para su venta o arriendo en el curso ordinario de los negocios de un otorgante, así como las materias primas y los bienes semielaborados (en fase de elaboración);

s) Por “conocimiento” se entenderá el conocimiento a ciencia cierta y no el conocimiento por deducción;

t) Por “masa o producto” se entenderán los bienes corporales que no sean dinero, que estén tan estrechamente unidos a otros bienes corporales, o mezclados con ellos, que hayan perdido su identidad propia;

u) Por “notificación” se entenderá toda comunicación hecha por escrito;

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que en el comentario se hará referencia al artículo 4 en relación con el equivalente electrónico de “escrito” y “escrito firmado” y también a la expresión “notificación” en el proyecto de Guía para un Registro.]

v) Por “notificación de la cesión” se entenderá la comunicación hecha por escrito en la que se especifique suficientemente el crédito por cobrar cedido y la identidad del cesionario;

w) Por “contrato originario” se entenderá, en el contexto de un crédito por cobrar establecido mediante contrato, el contrato celebrado entre el cedente y el deudor del crédito por cobrar del que nazca el crédito;

x) Por “posesión” se entenderá únicamente la posesión efectiva de bienes corporales por una persona o por un agente o empleado de esta, o bien por una persona independiente que reconozca que los conserva en nombre de tal persona. Este concepto no abarca la posesión no efectiva, que se describa con términos como deducible, ficticia, supuesta o simbólica;

y) Por “prelación” se entenderá el derecho de una persona a obtener un beneficio económico de su garantía real sobre un bien gravado con preferencia frente al derecho de otro reclamante concurrente;

z) Por “producto” se entenderá todo lo recibido que dimane de los bienes gravados, inclusive lo que se perciba a raíz de la venta o de otro acto de disposición o del cobro de los bienes gravados, de su arriendo o de una licencia otorgada sobre ellos, el producto del producto, los frutos o ingresos naturales y civiles, los dividendos que reporten, las distribuciones correspondientes, las sumas abonadas por compañías de seguros a título de indemnización y las reclamaciones presentadas

en concepto de defectos que presenten bienes gravados, de los daños que hayan sufrido y de la pérdida de los bienes en sí;

aa) Por “crédito por cobrar” se entenderá todo derecho al cumplimiento de una obligación monetaria, a excepción de los derechos de cobro documentados por un título negociable, todo derecho a percibir el producto de una promesa independiente y todo derecho al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria;

bb) Por “derecho a la retención de la titularidad” se entenderá el derecho de un vendedor sobre bienes, equipo o existencias conforme a un acuerdo con el comprador en virtud del cual la titularidad de ese bien no se transfiere (o no se transfiere irrevocablemente) del vendedor al comprador hasta que se haya abonado la parte no pagada del precio de compra del bien;

cc) Por “acreedor garantizado” se entenderá todo acreedor que tenga un derecho de garantía, inclusive un cesionario en virtud de una cesión pura y simple de un crédito por cobrar;

dd) Por “obligación garantizada” se entenderá toda obligación cuyo cumplimiento esté amparado por una garantía real;

ee) Por “operación garantizada” se entenderá toda operación por la que se constituya una garantía real, inclusive, para facilitar las consultas, toda cesión pura y simple de un crédito por cobrar, sin reclasificarla como una operación garantizada;

ff) Por “acuerdo de garantía” se entenderá un acuerdo concertado entre un otorgante y un acreedor, cualquiera que sea su forma o su terminología, en virtud del cual se constituya una garantía real, inclusive, para facilitar las consultas, un acuerdo de cesión pura y simple de un crédito por cobrar, sin recharacterizarlo como un acuerdo de garantía;

gg) Por “garantía real” se entenderá un derecho de propiedad sobre bienes muebles que se constituya mediante un acuerdo y que garantice el pago u otro tipo de cumplimiento de una obligación, independientemente de que las partes lo hayan calificado o no de garantía real, inclusive, para facilitar las consultas, el derecho del cesionario en virtud de una cesión pura y simple de un crédito por cobrar, sin reclasificarla como una garantía real y, [si el Estado promulgante adopta un enfoque unitario de la financiación de adquisiciones, las garantías reales del pago de adquisiciones y las no destinadas a adquisiciones] [pero no incluye ningún derecho de retención de la titularidad ni de arrendamiento financiero si el Estado promulgante adopta un enfoque no unitario de la financiación de adquisiciones];

hh) Por “bien corporal” se entenderá todo tipo de bienes muebles corporales, como los bienes, las existencias y los bienes de equipo.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que las referencias al enfoque unitario y no unitario de las operaciones garantizadas en las operaciones que figuran en los apartados a), b), h) ii), n), o), y bb) se han suprimido puesto que no encajan en una ley modelo. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si se debería hacer referencia a los enfoques unitario y no unitario entre corchetes, como se ha hecho en el apartado gg).]

Artículo 3. Autonomía contractual

1. Salvo disposición en contrario en los artículos 6, 7, 66, 79, 80, 103 a 132 y 134 a 146, el acreedor garantizado y el otorgante o el deudor podrán estipular entre ellos al margen de lo que la ley disponga acerca de sus respectivos derechos y obligaciones o modificarlos mediante acuerdo.
2. Lo estipulado en dicho acuerdo no afectará a los derechos de quien no sea parte en él.

Artículo 4. Comunicaciones electrónicas

1. Cuando la presente Ley requiera que una comunicación o un contrato conste por escrito, o prevea consecuencias en el caso de que ese no se cumpla, una comunicación electrónica cumplirá ese requisito si la información consignada en su texto es accesible para su ulterior consulta.
2. Cuando la presente Ley requiera que una comunicación o un contrato sea firmado por una persona, o prevea consecuencias en el caso de que no se firme, ese requisito se dará por cumplido respecto de una comunicación electrónica:
 - a) Si se utiliza un método para determinar la identidad de esa persona y para indicar la voluntad que tiene tal parte respecto de la información consignada en la comunicación electrónica; y
 - b) Si el método empleado:
 - i) O bien es tan fiable como sea apropiado para los fines para los que se generó o transmitió la comunicación electrónica, atendidas todas las circunstancias del caso, inclusive todo acuerdo aplicable; o
 - ii) Si se ha demostrado en la práctica que, por sí solo o con el respaldo de otras pruebas, dicho método ha cumplido las funciones enunciadas en el anterior apartado 2 a).

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que, con respecto al fondo del artículo 4, el comentario se referirá al artículo 9, párrafos 2 y 3, de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales.]

(A/CN.9/WG.VI/WP.55/Add.1) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de ley modelo sobre las operaciones garantizadas, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23º período de sesiones**ADICIÓN****Índice**

Capítulo II.	Constitución de una garantía real (eficacia entre las partes)
Artículo 5.	Constitución de una garantía real
Artículo 6.	Contenido mínimo de un acuerdo de garantía
Artículo 7.	Forma de un acuerdo de garantía
Artículo 8.	Obligaciones garantizadas por una garantía real
Artículo 9.	Bienes que pueden ser objeto de una garantía real
Artículo 10.	Aplicabilidad de una garantía real al producto del bien gravado
Artículo 11.	Constitución de una garantía real sobre un accesorio fijo y continuación de sus efectos
Artículo 12.	Vigencia de una garantía real extensible a una masa o un producto
Artículo 13.	Cesión global de créditos por cobrar
Artículo 14.	Cláusula de intransmisibilidad
Artículo 15.	Constitución de una garantía real sobre otro derecho personal o real por el que se respalde un crédito por cobrar
Capítulo III.	Oponibilidad de una garantía real a terceros
Artículo 16.	Eficacia de la oponibilidad a terceros
Artículo 17.	Eficacia frente al otorgante de una garantía real no oponible a terceros
Artículo 18.	Oponibilidad a terceros tras la transmisión del bien gravado
Artículo 19.	Método general para obtener la oponibilidad: inscripción registral
Artículo 20.	Otros métodos y excepciones a la vía registral
Artículo 21.	Diversidad de métodos para obtener la oponibilidad según la categoría del bien gravado
Artículo 22.	Oponibilidad de una garantía real sobre un bien corporal por posesión del bien gravado
Artículo 23.	Oponibilidad de una garantía real sobre un bien mueble que haya de inscribirse en un registro especial o anotarse en un certificado de titularidad
Artículo 24.	Oponibilidad automática de una garantía real sobre el producto de un bien gravado

- Artículo 25. Oponibilidad automática de una garantía real sobre un bien incorporado fijo . . .
- Artículo 26. Oponibilidad de una garantía real sobre un bien incorporado fijo sujeto a inscripción en un registro especial o a anotación en un certificado de titularidad.
- Artículo 27. Oponibilidad de una garantía real sobre un bien incorporado a un bien inmueble.
- Artículo 28. Oponibilidad automática de una garantía real sobre una masa de bienes o sobre un producto
- Artículo 29. Continuidad de la oponibilidad tras el traslado al territorio de este Estado
- Artículo 30. Continuidad de la oponibilidad de una garantía real a raíz de algún cambio en el método por el que se haya de obtener esa oponibilidad
- Artículo 31. Lapso en la oponibilidad de una garantía o inscripción por adelantado de la misma
- Artículo 32. Oponibilidad de una garantía real constituida sobre un derecho que garantice el pago de un crédito por cobrar.

Capítulo II. Constitución de una garantía real (eficacia entre las partes)

Artículo 5. Constitución de una garantía real

1. Toda garantía real sobre un bien quedará constituida mediante un acuerdo de garantía.
2. Si se trata de un bien respecto del cual el otorgante tenga derechos o la facultad para gravarlo en el momento de concertarse el acuerdo, la garantía real quedará constituida en el momento de celebrarse dicho acuerdo.
3. Si se trata de un bien respecto del cual el otorgante adquiriera derechos o la facultad para gravarlo con posterioridad al acuerdo, la garantía real sobre dicho bien quedará constituida cuando el otorgante adquiriera derechos sobre dicho bien o la facultad para gravarlo.

Artículo 6. Contenido mínimo de un acuerdo de garantía

Todo acuerdo de garantía deberá:

- a) Reflejar la intención de las partes de constituir una garantía real;
- b) Especificar la identidad del acreedor garantizado y del otorgante;
- c) Describir la obligación garantizada;
- d) Describir los bienes gravados de forma suficiente para poder identificarlos [; y
- e) Indicar el importe monetario máximo por el que puede ejecutarse la garantía real, si el Estado promulgante determina que tal indicación sería útil para facilitar los préstamos subordinados].

Artículo 7. Forma de un acuerdo de garantía

1. Un acuerdo de garantía podrá concertarse verbalmente si el acreedor garantizado tiene la posesión del bien gravado.
2. Si no va acompañado de la posesión del bien gravado, el acuerdo de garantía deberá concertarse por escrito, o deberá quedar alguna constancia escrita del mismo, que, por sí misma y juntamente con la conducta de las partes, ponga de manifiesto la intención del otorgante de constituir una garantía real.

Artículo 8. Obligaciones garantizadas por una garantía real

Una garantía real podrá garantizar cualquier tipo de obligaciones, presentes o futuras, determinadas o por determinar, condicionales o incondicionales, fijas o fluctuantes.

Artículo 9. Bienes que pueden ser objeto de una garantía real

1. Salvo en el caso de [toda excepción limitada y concreta que fije el Estado promulgante], se podrá gravar con una garantía real cualquier categoría de bienes, incluidos los siguientes:
 - a) Las partes de bienes y los derechos indivisos sobre los mismos;
 - b) Los bienes que, en el momento de concertarse el acuerdo de garantía, no existan todavía o no sean aún propiedad del otorgante ni gravables por él;
 - c) Todos los bienes del otorgante.
2. A reserva de lo dispuesto en los artículos 13 a 15, la presente Ley no anula lo dispuesto en cualquier otra ley que limite la constitución o la ejecución de una garantía real sobre determinada categoría de bienes o su transmisibilidad.

Artículo 10. Aplicabilidad de una garantía real al producto del bien gravado

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes en un acuerdo de garantía, la garantía real constituida sobre el bien gravado se hará extensiva a todo producto identificable del mismo, y también al producto de dicho producto.
2. Cuando el producto que esté en forma de dinero o de fondos acreditados en una cuenta bancaria se haya entremezclado con otros bienes del mismo tipo, de forma que el producto deje de ser identificable, el importe a que ascienda ese producto inmediatamente antes de ser mezclado se tendrá de cualquier modo por producto identificable con posterioridad a la mezcla;
3. Si algún momento posterior a la mezcla el importe total de los bienes pasa a ser inferior al importe del producto que se mezcló, se tendrá por producto identificable dicho importe total de los bienes, en el momento en que pasó a ser inferior, más el importe de todo producto posteriormente mezclado con esos bienes.

**Artículo 11. Constitución de una garantía real sobre un accesorio
fijo y continuación de sus efectos**

1. Podrá constituirse una garantía real sobre un bien corporal que, en el momento de ser gravado, sea un bien incorporado a otro, o la garantía seguirá gravando un bien corporal que ulteriormente pase a ser un bien incorporado a otro bien.
2. Podrá constituirse una garantía real sobre un bien incorporado a un bien inmueble tanto con arreglo a la presente Ley como en virtud del régimen legal de la propiedad inmobiliaria.

**Artículo 12. Vigencia de una garantía real extensible
a una masa o un producto**

1. Una garantía real constituida sobre bienes corporales antes de ser entremezclados en una masa o un producto seguirá gravando esa masa o producto.
2. El importe cubierto por una garantía real subsistente sobre dicha masa o producto quedará limitado al valor que hubieran tenido esos bienes gravados inmediatamente antes de pasar a formar parte de la masa o del producto.

Artículo 13. Cesión global de créditos por cobrar

1. Toda cesión de un crédito por cobrar contractual que no esté expresamente individualizado, o de un crédito futuro, una fracción de un crédito o un derecho indiviso sobre un crédito por cobrar, será exigible entre el cedente y el cesionario y oponible al deudor de todo crédito cedido, siempre que, en el momento de efectuarse la cesión, o en el momento en que nazca si es un crédito futuro, pueda determinarse que ese crédito corresponde a dicha cesión.
2. De no haberse estipulado otra cosa, toda cesión de uno o más créditos por cobrar futuros surtirá efecto sin que se requiera un nuevo acto de transmisión para ceder cada uno de los créditos por cobrar¹.

Artículo 14. Cláusula de intransmisibilidad

1. Una cesión de un crédito por cobrar surtirá efecto entre el cedente y el cesionario, así como frente al deudor del crédito cedido, pese a todo pacto concertado entre el cedente inicial o todo cedente subsiguiente y el deudor del crédito o cualquier cesionario subsiguiente del crédito, por el que se limite de algún modo el derecho del cedente a ceder sus créditos por cobrar.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo menoscabará en modo alguno la obligación o la responsabilidad que pueda tener el cedente por el incumplimiento de lo estipulado en el pacto mencionado en el párrafo 1 del presente artículo, pero la otra parte en dicho pacto no podrá impugnar el contrato originario ni el contrato de cesión únicamente por razón de ese incumplimiento. Toda persona que no sea parte en el mencionado pacto no incurrirá en responsabilidad alguna por el mero hecho de haber tenido conocimiento de dicho pacto.

¹ Con respecto a los artículos 13 a 15, véanse los artículos 8 a 10 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos.

3. El presente artículo será aplicable únicamente a la cesión de créditos por cobrar:

a) Nacidos de un contrato originario que sea un contrato para el suministro o el arrendamiento de bienes o para la prestación de servicios que no sean de carácter financiero, o que sea un contrato de obras o para la venta o el arrendamiento de un inmueble;

b) Nacidos de un contrato originario para la venta, el arrendamiento o la licencia de derechos de propiedad industrial o intelectual, o de información de dominio privado;

c) Que representen la obligación de pago de una operación efectuada con tarjeta de crédito; o

d) Adeudados al cedente por concepto del saldo neto de los pagos debidos en virtud de un acuerdo de compensación global por saldos netos concertado entre más de dos partes.

Artículo 15. Constitución de una garantía real sobre otro derecho personal o real por el que se respalde un crédito por cobrar

1. El acreedor garantizado que tenga una garantía real sobre un crédito por cobrar se beneficiará de todo derecho personal o real por el que se garantice automáticamente el pago u otra forma de cumplimiento de dicho crédito por cobrar, sin necesidad de otro acto del otorgante o del acreedor garantizado.

2. Si el derecho personal o real es una promesa independiente, la garantía real se hará automáticamente extensiva al derecho a percibir el producto de dicha promesa, pero no al derecho al cobro de la misma.

3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al derecho sobre un bien inmueble que, con arreglo a la ley que se le sea aplicable, pueda transmitirse por separado del crédito por cobrar que garantice.

4. Todo acreedor garantizado que posea una garantía real sobre un crédito por cobrar pasará a ser el beneficiario de cualquier derecho personal o real que garantice el pago o alguna otra forma de cumplimiento de dicho crédito por cobrar, incluso si existe pacto entre el otorgante y el deudor del crédito por el que se limite de algún modo el derecho del otorgante a constituir una garantía real sobre el crédito, o sobre cualquier derecho real o personal por el que se garantice el pago u otra forma de cumplimiento del crédito por cobrar.

5. Nada de lo dispuesto en el presente artículo menoscabará en modo alguno la obligación o la responsabilidad del otorgante por el incumplimiento del pacto mencionado en el párrafo 4 del presente artículo, pero la otra parte en dicho pacto no podrá impugnar el contrato del que nazca el crédito por cobrar, ni el acuerdo de garantía constitutivo de la garantía real o personal, por el mero hecho del incumplimiento de dicho pacto. Toda persona que no sea parte en el mencionado pacto no incurrirá en responsabilidad alguna por el mero hecho de haber tenido conocimiento del pacto.

6. Los párrafos 4 y 5 del presente artículo serán aplicables únicamente a las garantías reales constituidas sobre créditos por cobrar:

a) Dimanantes de un contrato originario que sea un contrato para el suministro o el arrendamiento de bienes o para la prestación de servicios que no sean de carácter financiero, o que sea un contrato de obras o un contrato para la venta o el arrendamiento de un inmueble;

b) Dimanantes de un contrato originario para la venta, el arrendamiento o la concesión de una licencia de derechos de propiedad industrial o intelectual o de información de dominio privado;

c) Que representen una obligación de pago de una operación efectuada con tarjeta de crédito; o

d) Adeudados al cedente por concepto del saldo neto de los pagos debidos en virtud de un acuerdo de liquidación global por saldos netos concertado entre más de dos partes.

7. Lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no afectará a obligación alguna contraída por el otorgante frente al deudor del crédito por cobrar.

8. Siempre que no se reste validez a los efectos automáticos previstos en el párrafo 1 del presente artículo y en el artículo 32, el presente artículo no afectará a las disposiciones de ninguna otra ley en cuanto a la forma o a la inscripción registral de la constitución de una garantía real sobre cualquier bien, que garantice el pago u otra forma de cumplimiento de un crédito por cobrar al que no se aplique la presente Ley.

Capítulo III. Oponibilidad de una garantía real a terceros

Artículo 16. Eficacia de la oponibilidad a terceros

Una garantía real solo será oponible a terceros cuando haya sido constituida y se haya seguido alguno de los métodos previstos en los artículos 19, 21 o 22 para establecer su oponibilidad.

Artículo 17. Eficacia frente al otorgante de una garantía real no oponible a terceros

Una garantía real que haya sido constituida será exigible por el acreedor garantizado frente al otorgante de la garantía, aun cuando esa garantía no sea oponible a terceros.

Artículo 18. Oponibilidad a terceros tras la transmisión del bien gravado

Una vez transmitido un derecho que no sea una garantía real sobre un bien gravado, toda garantía real sobre ese bien gravado que sea oponible a terceros en el momento de dicha transmisión seguirá gravando el bien, a reserva de lo dispuesto en el artículo 50, y seguirá siendo eficaz frente a terceros, a reserva de lo dispuesto en el artículo 39.

**Artículo 19. Método general para obtener la oponibilidad:
inscripción registral**

1. Una garantía real será oponible a terceros si se inscribe una notificación respecto de esa garantía en el registro general de las garantías reales mencionado en los artículos 33 a 47.
2. La inscripción registral de una notificación no crea una garantía real ni es necesaria para su constitución.

Artículo 20. Otros métodos y excepciones a la vía registral

1. Cabrá también obtener la oponibilidad a terceros de una garantía real por alguno de los demás métodos siguientes:
 - a) Si se trata de bienes corporales, mediante la posesión por el acreedor garantizado, conforme a lo previsto en el artículo 22;
 - b) Si se trata de bienes muebles, los derechos sobre los cuales estén sujetos a inscripción en un registro especial o que hayan de ser anotados en un certificado de titularidad, mediante dicha inscripción registral o anotación, conforme a lo previsto en el artículo 23;
 - c) Si se trata de un bien incorporado a un bien mueble, los derechos sobre el cual estén sujetos a inscripción en un registro especial o que hayan de ser anotados en un certificado de titularidad, mediante dicha inscripción registral o anotación, conforme a lo previsto en el artículo 26; y
 - d) Si se trata de un bien incorporado a un bien inmueble, mediante su inscripción en el registro de la propiedad inmobiliaria, conforme a lo previsto en el artículo 27.
2. Una garantía real será automáticamente oponible a terceros:
 - a) Si se trata del producto reportado por el bien originariamente gravado, siempre que la garantía real sobre dicho bien sea oponible a terceros, conforme a lo previsto en el artículo 24;
 - b) Si se trata de un bien incorporado a otro bien mueble, siempre que la garantía real sobre él fuera oponible a terceros antes de que dicho bien pasara a ser un bien incorporado fijo, conforme a lo previsto en el artículo 25;
 - c) Si se trata de una masa de productos o de un producto acabado, siempre que la garantía real sobre los bienes elaborados o entremezclados fuera oponible a terceros antes de que esos bienes pasaran a formar parte de la masa o del producto, conforme a lo previsto en el artículo 28; y
 - d) Si se trata de bienes muebles, en caso de trasladarse el otorgante o de ser trasladados esos bienes al territorio de este Estado, conforme a lo previsto en el artículo 29.
3. Toda garantía real constituida sobre un derecho personal o real que garantice el pago o alguna otra forma de cumplimiento de un crédito por cobrar será oponible a terceros, conforme a lo previsto en el artículo 32.

Artículo 21. Diversidad de métodos para obtener la oponibilidad según la categoría del bien gravado

Podrían utilizarse diversos métodos, para obtener la oponibilidad de diferentes categorías de bienes gravados, con independencia de que esos bienes fueran o no gravados en virtud de un mismo acuerdo de garantía.

Artículo 22. Oponibilidad de una garantía real sobre un bien corporal por posesión del bien gravado

Una garantía real sobre un bien corporal podrá hacerse oponible a terceros mediante su inscripción registral, conforme a lo previsto en el artículo 19, o poniendo el bien gravado en posesión del acreedor garantizado.

Artículo 23. Oponibilidad de una garantía real sobre un bien mueble que haya de inscribirse en un registro especial o anotarse en un certificado de titularidad

Una garantía real sobre un bien mueble que haya de inscribirse en un registro especial o anotarse en un certificado de titularidad, con arreglo a otra ley aplicable, podrá hacerse oponible a terceros por inscripción registral, conforme a lo previsto en el artículo 19, o mediante:

- a) Su inscripción en el registro especial; o
- b) Su anotación en el certificado de titularidad.

Artículo 24. Oponibilidad automática de una garantía real sobre el producto de un bien gravado

1. Si una garantía real sobre un bien gravado es oponible a terceros, la garantía sobre cualquier producto de dicho bien (inclusive sobre el producto que reporte dicho producto) será oponible a terceros al nacer ese producto, siempre y cuando el producto haya sido descrito en términos genéricos en una notificación inscrita en el registro o el producto consista en dinero, créditos por cobrar, títulos negociables o el derecho al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria.
2. Si el producto no ha sido descrito en una notificación inscrita, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, y no consiste en dinero, créditos por cobrar, títulos negociables ni derechos al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria, la garantía real sobre el producto seguirá siendo oponible a terceros durante [un breve plazo que habrá de indicar el Estado promulgante] días a partir del nacimiento del producto.
3. Si la garantía real sobre ese producto se hace oponible a terceros por alguno de los métodos señalados en los artículos 19 o 20 antes de vencer ese plazo, dicha garantía real sobre el producto seguirá siendo eficaz frente a terceros con posterioridad a ese plazo.

Artículo 25. Oponibilidad automática de una garantía real sobre un bien incorporado fijo

De ser oponible a terceros una garantía real sobre un bien corporal al pasar dicho bien a ser un bien incorporado fijo, esa garantía real seguirá siendo oponible con posterioridad.

Artículo 26. Oponibilidad de una garantía real sobre un bien incorporado fijo sujeto a inscripción en un registro especial o a anotación en un certificado de titularidad

Una garantía real sobre un bien incorporado a otro bien mueble que, conforme a otra ley, esté sujeto a inscripción en un registro especial o que haya de ser anotado en un certificado de titularidad, podrá hacerse automáticamente oponible, conforme a lo previsto en el artículo 25 o por:

- a) Inscripción en el registro especial; o
- b) Anotación en el certificado de titularidad.

Artículo 27. Oponibilidad de una garantía real sobre un bien incorporado a un bien inmueble

Una garantía real sobre un bien incorporado a un inmueble pasará a ser automáticamente oponible a terceros conforme a lo previsto en el artículo 25 o mediante su inscripción en el registro de la propiedad inmobiliaria.

Artículo 28. Oponibilidad automática de una garantía real sobre una masa de bienes o sobre un producto

Si una garantía real sobre un bien corporal es oponible a terceros en el momento en que ese bien pasa a formar parte de una masa de bienes o de un producto, dicha garantía real seguirá siendo oponible a terceros conforme a lo dispuesto en el artículo 12.

Artículo 29. Continuidad de la oponibilidad tras el traslado al territorio de este Estado

1. Si una garantía constituida sobre un bien gravado es oponible a terceros con arreglo a la ley del Estado en que se encuentre el bien gravado o el otorgante de la garantía (según cuál de los dos determine la ley aplicable en virtud de las normas correspondientes sobre conflictos de leyes) y dicho bien o dicho otorgante se traslada al territorio de este Estado, la garantía real seguirá siendo oponible a terceros a tenor de la ley del nuevo foro, durante [un breve plazo que habrá de especificar el Estado promulgante] días a partir de dicho traslado.
2. Si se cumplen antes de vencer ese plazo los requisitos previstos en la legislación de este Estado para que la garantía real sea oponible a terceros, esa garantía real seguirá siéndolo con arreglo a la ley de este Estado.
3. A efectos de toda regla de este Estado por la cual se deba tener en cuenta, a fin de determinar la prelación de la garantía, el momento de su inscripción o de cumplimiento de otro requisito para lograr su oponibilidad a terceros, ese momento será aquel en que se efectuó la inscripción o se obtuvo la oponibilidad conforme a la

ley del Estado en que se encontraban el bien gravado o el otorgante antes de su traslado al territorio de este Estado.

Artículo 30. Continuidad de la oponibilidad de una garantía real a raíz de algún cambio en el método por el que se haya de obtener esa oponibilidad

La garantía real seguirá siendo oponible a terceros aunque cambie el método por el que se haya de obtener esa oponibilidad, siempre que no haya habido alguna interrupción de esa oponibilidad.

Artículo 31. Lاپso en la oponibilidad de una garantía o inscripción por adelantado de la misma

1. Si una garantía real pasa a ser oponible, pero pierde esa oponibilidad durante cierto lapso de tiempo, podrá restablecerse la oponibilidad, pero solo desde el momento en que la nueva inscripción registral de una notificación relativa a esa garantía real haya adquirido validez.
2. Si, conforme a lo dispuesto en el artículo 44, una inscripción registral efectuada, con arreglo al artículo 42, antes de constituirse una garantía real expira, dicha inscripción podrá revalidarse, pero la inscripción registral surtirá efecto a partir del momento en que se haya inscrito una nueva notificación relativa a esa garantía real.

Artículo 32. Oponibilidad de una garantía real constituida sobre un derecho que garantice el pago de un crédito por cobrar

- 1 Si una garantía real sobre un crédito por cobrar es oponible a terceros, dicha oponibilidad será extensiva a todo derecho personal o real que garantice el pago u otra forma de cumplimiento de dicho crédito por cobrar sin necesidad de otro acto del otorgante o el acreedor garantizado.
2. Si el derecho personal o real es una promesa independiente, su oponibilidad a terceros será automáticamente extensiva al producto de esa promesa, pero esa garantía real no será extensiva al derecho al cobro de dicha promesa independiente.
3. El presente artículo no afectará a derecho alguno sobre un bien inmueble que conforme a otra ley sea transmisible por separado del crédito por cobrar que garantice.

(A/CN.9/WG.VI/WP.55/Add.2) (Original: inglés)

**Nota de la Secretaría sobre el proyecto de ley modelo sobre las
operaciones garantizadas, presentada al Grupo de Trabajo
sobre Garantías Reales en su 23º período de sesiones**

ADICIÓN

Índice

Capítulo IV.	El sistema registral.
Artículo 33.	Marco funcional de los procesos de inscripción registral y consulta
Artículo 34.	Seguridad e integridad del registro
Artículo 35.	Responsabilidad en caso de pérdida o daño.
Artículo 36.	Contenido obligatorio de una notificación.
Artículo 37.	Identificador del otorgante
Artículo 38.	Consecuencias de una modificación del identificador del otorgante en la eficacia de la inscripción registral.
Artículo 39.	Consecuencias de una transmisión de un bien gravado en la eficacia de la inscripción registral.
Artículo 40.	Descripción de un bien gravado objeto de una notificación.
Artículo 41.	Consecuencias de una indicación incorrecta o de una descripción insuficiente
Artículo 42.	Momento en que podrá inscribirse una notificación
Artículo 43.	Suficiencia de una única notificación respecto de diversas garantías reales nacidas de más de un acuerdo entre las mismas partes
Artículo 44.	Plazo de eficacia de la inscripción registral de una notificación
Artículo 45.	Momento en que surtirá efecto la inscripción registral de una notificación.
Artículo 46.	Autorización para efectuar la inscripción registral de una notificación
Artículo 47.	Modificación y cancelación de una notificación

Capítulo IV. El sistema registral

Artículo 33. Marco funcional de los procesos de inscripción registral y consulta

1. El registro deberá poner a disposición del público directrices claras y concisas sobre los procedimientos de inscripción registral y consulta y difundir ampliamente información sobre la existencia y función del registro.
2. La inscripción registral será válida mediante la anotación de una notificación que facilite la información especificada en el artículo 36, sin necesidad de que se presente el original o una copia del acuerdo de garantía o de algún otro documento.

3. El registro estará obligado a aceptar toda notificación presentada por algún medio de comunicación autorizado, salvo que la notificación:
 - a) No vaya acompañada de la tasa de inscripción exigible;
 - b) No facilite un identificador del otorgante que sea suficiente para poder indexarlo en un índice; o
 - c) No facilite alguna información con respecto a cualquiera de los demás datos exigibles en virtud del artículo 36.
4. El registro no podrá exigir que se verifique la identidad del solicitante de la inscripción ni la existencia de autorización para la inscripción de la notificación, ni investigar más a fondo el contenido de la notificación.
5. El fichero del registro estará centralizado y contendrá todas las notificaciones con respecto a garantías reales inscritas de conformidad con la presente Ley.
6. La información facilitada en el fichero del registro accesible al público podrá ser consultada por las personas que lo deseen.
7. Se podrá realizar una consulta sin necesidad de que el usuario justifique las razones de la búsqueda.
8. Las notificaciones se indexarán y los autores de consultas podrán recuperarlas en función del identificador del otorgante.
9. Las tasas de inscripción registral y de consulta, si las hubiere, se fijarán a un nivel no superior al necesario para cubrir los gastos del registro.
10. De ser posible, el sistema de inscripción registral será electrónico. En particular:
 - a) Las notificaciones se almacenarán en forma electrónica en una base de datos informática;
 - b) Los autores de una inscripción y las personas que realicen una consulta tendrán acceso inmediato al fichero del registro por medios electrónicos o similares, como Internet o el intercambio electrónico de datos;
 - c) El sistema estará programado para minimizar el riesgo de inserción de información incompleta o intrascendente; y
 - d) El sistema se programará para facilitar la recuperación rápida y completa de la información y minimizar las consecuencias prácticas de los errores humanos.
11. Los autores de inscripciones podrán elegir entre múltiples modalidades y puntos de acceso al registro.
12. El registro, en la medida en que sea electrónico, funcionará ininterrumpidamente, salvo para su mantenimiento regular, y, en la medida en que no sea electrónico, funcionará durante un horario de servicio fiable y regular que sea compatible con las necesidades de los posibles usuarios del registro.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que los artículos 33 a 47 se basan en las recomendaciones 54 a 75 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas y las recomendaciones del proyecto de Guía sobre un registro. En cuanto al artículo 33, el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la

posibilidad de que se armonizara estrechamente con las recomendaciones 4 a 10 del proyecto de Guía sobre un registro y si podría dejarse que algunos de los asuntos tratados en el artículo 33 (y otros artículos) se abordaran en las recomendaciones del proyecto de Guía sobre un registro y en el comentario del proyecto de Ley Modelo. Además, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si algunos de los asuntos que se tratan en las recomendaciones del proyecto de Guía sobre un registro, como, por ejemplo, la diferencia entre el acceso a los servicios del registro y el rechazo de una notificación, el plazo de vigencia de una inscripción registral, la información exigible en una notificación inicial en contraposición a una notificación de modificación o de cancelación, los criterios de consulta y los resultados de las consultas deberían abordarse en el proyecto de Ley Modelo, aunque no se trataron en detalle en las recomendaciones de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas.]

Artículo 34. Seguridad e integridad del registro

A fin de garantizar la seguridad e integridad del registro, su marco funcional y jurídico deberá reflejar las siguientes características:

- a) Si bien cabrá delegar en alguna entidad privada la gestión cotidiana del registro, el Estado retendrá la responsabilidad de asegurar que funcione con arreglo al marco jurídico vigente;
- b) El registro exigirá y anotará [información sobre] la identidad del solicitante de la inscripción;
- c) El solicitante de la inscripción estará obligado a enviar una copia de la notificación al otorgante mencionado en la misma, pero el incumplimiento de esta obligación podrá dar únicamente lugar a sanciones nominales y a la indemnización de todo daño probado que haya resultado de dicho incumplimiento;
- d) El registro estará obligado a enviar prontamente una copia de toda modificación de una notificación inscrita a la persona que se indique como acreedor garantizado en la notificación;
- e) El autor de una inscripción podrá obtener constancia de la inscripción tan pronto como la información pertinente haya sido incorporada al fichero del registro; y
- f) Se mantendrán varias copias de toda la información contenida en los ficheros de un registro y la totalidad de los ficheros del registro se podrá reconstruir en caso de pérdida o daño.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si el asunto tratado en el apartado a) de este artículo se debería abordar en el comentario y no en el proyecto de Ley Modelo propiamente dicho, y si los asuntos tratados en los demás apartados se deberían abordar de forma general o de forma detallada, pero más en consonancia con las recomendaciones del proyecto de Guía sobre un registro.]

Artículo 35. Responsabilidad en caso de pérdida o daño

1. Si el sistema del registro permite la inscripción registral y la consulta directas por los usuarios del registro sin intervención alguna del personal del registro, la

responsabilidad del registro en caso de pérdida o daño quedará limitada al mal funcionamiento del sistema.

2. Si el sistema del registro permite la presentación de notificaciones en papel, el registro será responsable de toda pérdida o daño causado por un error en la incorporación al fichero del registro de la información consignada en una notificación.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que este artículo se basa en la recomendación 56 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, que, no obstante, se ocupa únicamente del asunto tratado en el párrafo 1 de este artículo. Se ha añadido el párrafo 2 para completar el artículo 35. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si debería retenerse el artículo 35 o si el asunto debería dejarse en manos de otra ley del Estado promulgante. Si el Grupo de Trabajo decide retener el artículo 35, tal vez desee examinar su fondo.]

Artículo 36. Contenido obligatorio de una notificación

La notificación deberá contener únicamente la siguiente información obligatoria:

a) El identificador del otorgante, que cumpla el criterio previsto en el artículo 37 [y la demás información que especifique el Estado promulgante para ayudar a identificar inequívocamente al otorgante];

b) El identificador del acreedor garantizado o de su representante, sus direcciones;

c) Una descripción del bien gravado objeto de la notificación, que cumpla lo prescrito en el artículo 40;

d) [Si el Estado promulgante opta por la variante B o C del artículo 44, el plazo de vigencia de la inscripción registral conforme a lo previsto en el artículo 44;] y

e) [Si el Estado promulgante determina que sería útil indicar en la notificación el importe monetario máximo por el que se puede ejecutar la garantía real a fin de facilitar los préstamos subordinados, una declaración de ese importe máximo].

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que la referencia a información complementaria en la notificación para ayudar a identificar inequívocamente al otorgante se ha añadido al apartado a) y se ha suprimido del artículo 37, párrafo 2. Esos cambios tienen por objetivo recoger las decisiones del Grupo de Trabajo con respecto a la recomendación 23, apartado a) i), del proyecto de Guía sobre un registro con el fin de evitar que la información complementaria pase a formar parte del identificador del otorgante y, de esa forma, a ser un criterio de consulta.]

Artículo 37. Identificador del otorgante

1. La inscripción registral de una notificación inicial, o de una notificación de modificación que modifique el identificador del otorgante o añada un otorgante, solo surtirá efecto si en la notificación se facilita el identificador correcto del

otorgante de conformidad con los párrafos 2 y 3 del presente artículo, o, en el caso de una indicación incorrecta, si cumple los requisitos del artículo 41, párrafos 1 y 2.

2. Si el otorgante es una persona física, el identificador del otorgante requerido para que la inscripción registral surta efecto será el nombre del otorgante, tal como figure en un documento oficial especificado.

3. Si el otorgante es una persona jurídica, el identificador del otorgante requerido para que la inscripción registral surta efecto será el nombre que figure en el [documento, ley o decreto que especifique el Estado promulgante] más reciente por el que se haya constituido la persona jurídica.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que las modificaciones de los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo (en comparación con las recomendaciones 58 a 60 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas en las que se basan) tienen el objetivo de armonizarlos respectivamente con las recomendaciones 29, 23, apartado a) i), y 25 del proyecto de guía sobre un registro. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si debería añadirse un artículo similar a los párrafos 2 y 3 de este artículo para tratar el identificador del acreedor asegurado, mientras que los efectos de una indicación incorrecta se pueden seguir abordando en el artículo 41.]

Artículo 38. Consecuencias de una modificación del identificador del otorgante en la eficacia de la inscripción registral

1. Si, después de inscribirse la notificación, el identificador del otorgante se modifica, y, si a consecuencia de esa modificación, el identificador del otorgante indicado en la notificación no cumple lo previsto en el artículo 37, el acreedor asegurado [podrá] [deberá] modificar la notificación para facilitar el nuevo identificador en cumplimiento de lo dispuesto en ese artículo.

2. Si el acreedor garantizado no hace inscribir la modificación dentro de los [un breve plazo, por ejemplo 30 días, que deberá especificar el Estado promulgante] días siguientes a la modificación, la garantía real no será oponible:

a) Al titular de una garantía real concurrente respecto de la cual se haya inscrito una notificación o que se haya hecho de algún otro modo oponible a terceros después de la modificación del identificador del otorgante, pero antes de haberse inscrito la notificación de modificación; y

b) A una persona que compre, arriende o ponga bajo licencia el bien gravado después de la modificación del identificador del otorgante, pero antes de haberse inscrito la notificación de modificación.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar que, aunque la recomendación 61 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas deja una modificación a discreción del acreedor asegurado, debe inscribirse una modificación para evitar las consecuencias descritas en el párrafo 2.]

**Artículo 39. Consecuencias de una transmisión de un bien gravado
en la eficacia de la inscripción registral**

Variante A

1. Si, después de haberse inscrito una notificación, el bien gravado se transfiere y una consulta que realicen terceros utilizando el nombre del beneficiario de la transmisión no divulga la garantía real constituida por el cedente, el acreedor garantizado deberá modificar la notificación para facilitar el identificador del beneficiario de la transmisión como nuevo otorgante.

2. Si el acreedor garantizado no hace inscribir la notificación de modificación en un plazo de modificación dentro de los [un breve plazo que deberá especificar el Estado promulgante] días siguientes a la transmisión del bien gravado, la garantía real no será oponible:

a) Al titular de una garantía real concurrente respecto de la cual se haya inscrito una notificación o que se haya hecho oponible de otra forma a terceros después de la transmisión pero antes de la inscripción registral de la notificación de modificación; y

b) A una persona que compre, arriende o ponga bajo licencia el bien gravado después de su transmisión, pero antes de la inscripción registral de la notificación de modificación.

Variante B

1. Si, después de haberse inscrito una notificación, el bien gravado se transfiere y una consulta realizada por terceros utilizando el nombre del beneficiario de la transmisión no divulga la garantía real constituida por el cedente, el acreedor garantizado deberá modificar la notificación para facilitar el identificador del beneficiario de la transmisión como nuevo otorgante.

2. Si el acreedor garantizado no hace inscribir la notificación de modificación dentro de los [un breve plazo, por ejemplo 15 días, que deberá especificar el Estado promulgante] días siguientes a *que el acreedor garantizado haya tenido conocimiento a ciencia cierta* de la transmisión del bien gravado, la garantía real no será oponible:

a) Al titular de una garantía real concurrente respecto de la cual se haya inscrito una notificación o que se haya hecho oponible a terceros de otra forma después de la transmisión, pero antes de la inscripción registral de la notificación de modificación; y

b) A una persona que compre, arriende o ponga bajo licencia el bien gravado después de su transmisión, pero antes de la inscripción registral de la notificación de modificación.

Variante C

La inscripción registral de una notificación en el registro de las garantías reales mantiene su eficacia aun en caso de transmisión del bien gravado.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que: a) el artículo 39 refleja los tres enfoques de la cuestión analizados en el

comentario de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas (véase el cap. IV, párrs. 78 a 80), dado que la recomendación 62 de esa Guía había dejado el asunto a la discreción de cada Estado; b) la diferencia entre las variantes A y B reside en el texto que figura en cursiva en la opción B; y c) la recomendación 244 del Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual refleja la variante C.]

Artículo 40. Descripción de un bien gravado objeto de una notificación

La inscripción registral de una notificación inicial, o una notificación de modificación que afecte a la descripción de los bienes gravados, surtirá efecto si en la notificación se describen los bienes gravados de forma que permita razonablemente identificarlos, y, en caso contrario, si cumple los requisitos del artículo 41, párrafo 3.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que este artículo, que se basa en la recomendación 63 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, ha sido revisado para armonizarlo con la formulación del artículo 37 y tratar la descripción del bien gravado, dejando las consecuencias de una descripción insuficiente para el artículo 41, párrafo 3.]

Artículo 41. Consecuencias de una indicación incorrecta o de una descripción insuficiente

1. Una indicación incorrecta del identificador del otorgante en una notificación no privará de eficacia a la inscripción registral si la notificación pudiera recuperarse mediante una consulta del fichero del registro utilizando el identificador correcto.
2. Un identificador incorrecto de un otorgante en una notificación no priva de eficacia a la inscripción registral con respecto a otros otorgantes identificados correctamente en la notificación.
3. Una indicación incorrecta del identificador o la dirección del acreedor asegurado o su representante, o una descripción del bien gravado que no cumpla los requisitos del artículo 40 en una notificación no privará de eficacia a la inscripción registral a menos que tal indicación incorrecta o insuficiente indujera a grave error a toda persona que consultara razonablemente el registro.
4. Una descripción de determinados bienes gravados que no cumpla los requisitos del artículo 40 no privará de eficacia a una inscripción registral con respecto a otros bienes que estén suficientemente descritos.
5. Una indicación incorrecta en una notificación con respecto al plazo de vigencia de la inscripción registral y el importe máximo por el que se puede ejecutar la garantía real, si es aplicable, no privará de eficacia a una notificación inscrita salvo en la medida en que hubiera inducido a grave error a los terceros que hubieran confiado en la notificación inscrita.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que las modificaciones efectuadas en este artículo (en comparación con las recomendaciones 64 a 66, en las que se basa) tienen por objetivo armonizarlo con la recomendación 29 del proyecto de Guía sobre un registro. El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que el “criterio de inducir a grave error” en el contexto del párrafo 5 es objetivo, mientras que el “criterio de inducir a grave error” del

párrafo 3 es subjetivo (véase la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, cap. IV, párrs. 84 y 96) y considerar si este asunto debería reflejarse de forma más explícita en este artículo y explicarse en el comentario pertinente que se ha de preparar.]

Artículo 42. Momento en que podrá inscribirse una notificación

Una notificación con respecto a una garantía real podrá inscribirse antes o después de la constitución de la garantía real o de la concertación del acuerdo de garantía.

Artículo 43. Suficiencia de una única notificación respecto de diversas garantías reales nacidas de más de un acuerdo entre las mismas partes

Bastará con hacer inscribir en el registro una única notificación para dotar de eficacia frente a terceros a una o más garantías reales sobre el bien gravado descrito en la notificación, ya estén constituidas en el momento de la inscripción registral o se constituyan ulteriormente, o nazcan de uno o más acuerdos de garantía concertados entre las mismas partes.

Artículo 44. Plazo de eficacia de la inscripción registral de una notificación

Variante A

1. La inscripción registral de una notificación inicial surtirá efecto durante [el Estado promulgante insertará el plazo especificado en su ley].
2. El plazo de vigencia podrá prorrogarse durante [un plazo adicional especificado en la ley del Estado promulgante] en cualquier momento antes de que expire. El nuevo plazo se iniciará cuando expire el plazo en curso.
- [3. Una modificación de notificación que no sea una modificación de notificación mencionada en el párrafo 2 del presente artículo no prorrogará el plazo de vigencia.]

Variante B

1. La inscripción registral de una notificación inicial surtirá efecto durante el plazo indicado en la misma.
2. El plazo de vigencia podrá prorrogarse o reducirse durante el plazo indicado en una notificación de modificación en cualquier momento antes de que expire. En caso de prórroga, el nuevo plazo se iniciará cuando expire el plazo en curso.
- [3. Una notificación de modificación que no sea una notificación de modificación mencionada en el párrafo 2 del presente artículo no prorrogará el plazo de vigencia.]

Variante C

1. La inscripción registral de una notificación inicial surtirá efecto durante el plazo indicado en la misma, que no será superior a [un plazo prolongado, como, por ejemplo, 20 años, que especificará el Estado promulgante].
2. El plazo de vigencia podrá prorrogarse o reducirse durante el plazo indicado en una notificación de modificación que no superará [un período prolongado, como, por ejemplo, 20 años, que especificará el Estado promulgante] en cualquier

momento antes de que expire el plazo de vigencia de la inscripción registral. En caso de prórroga, el nuevo plazo se inicia cuando expire el plazo en curso.

[3. Una notificación de modificación que no sea una notificación de modificación mencionada en el párrafo 2 del presente artículo no prorrogará el plazo de vigencia.]

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que el artículo 44 se basa en la recomendación 13 del proyecto de Guía sobre un registro, que a su vez se basa en la recomendación 69 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas.]

Artículo 45. Momento en que surtirá efecto la inscripción registral de una notificación

La inscripción registral de una notificación surtirá efecto cuando la información consignada en la notificación se incorpore al fichero del registro de modo que [esté disponible] [sea accesible] a las personas que consulten el fichero del registro accesible al público.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si se debería incluir en el artículo 45 un texto similar al de las recomendaciones 11, apartados b) y c) (el registro anotará la fecha y hora en que la inscripción registral comience a surtir efecto e incorporará las notificaciones en el orden en que se hayan recibido), y 12 (el registro asignará un número de inscripción a la notificación inicial) del proyecto de Guía sobre un registro. El Grupo de Trabajo tal vez desee también considerar el texto entre corchetes en este artículo, habida cuenta de la formulación de las recomendaciones 11, apartado a), y 16 del proyecto de Guía sobre un registro.]

Artículo 46. Autorización para efectuar la inscripción registral de una notificación

1. La inscripción registral de una notificación no será eficaz a menos que el otorgante la haya autorizado por escrito.
2. La inscripción registral de una notificación de modificación en la que [describir las modificaciones] no será eficaz a menos que la haya autorizado el otorgante.
3. La inscripción registral de una notificación de cancelación no será eficaz a menos que la haya autorizado el acreedor garantizado o la haya ordenado una autoridad judicial o administrativa de conformidad con el artículo 47, párrafo 3.
4. La autorización podrá concederse antes o después de la inscripción registral.
5. Un acuerdo de garantía escrito será suficiente para autorizar la inscripción registral.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que el artículo 46 se basa en la recomendación 71 y considerar la posibilidad de abordar: a) la cuestión de la autorización de una notificación de modificación por el otorgante o el acreedor garantizado; b) las consecuencias de la inexistencia de esa autorización por el acreedor garantizado (o fraude) en la eficacia de una notificación de modificación (véase la nota para el Grupo de Trabajo después de la recomendación 19 en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.5; véase la nota al

artículo 60 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.55/Add.3; y c) la cuestión de la autorización de una notificación de cancelación por el acreedor garantizado.]

Artículo 47. Modificación y cancelación de una notificación

1. El acreedor garantizado estará obligado a inscribir una notificación de modificación o de cancelación, según proceda, si:

a) La inscripción registral de una notificación inicial o de modificación no hubiera sido autorizada por el otorgante en absoluto o en la medida descrita en la notificación;

b) La inscripción registral de una notificación inicial o de modificación hubiera sido autorizada por el otorgante, pero la autorización hubiera sido retirada o no se hubiera concertado un acuerdo de garantía;

c) Se hubiera revisado el acuerdo de garantía y, debido a esa revisión, la información consignada en la notificación fuera incorrecta o insuficiente; o

d) La garantía real relacionada con la notificación se hubiera extinguido por el pago, por otro cumplimiento de la obligación garantizada, o de alguna otra manera, y no existiera compromiso alguno de conceder más crédito.

2. El acreedor asegurado estará obligado a inscribir en el registro una notificación de modificación o de cancelación, en la medida en que proceda, a más tardar [un breve plazo, como, por ejemplo, 15 días, que especificará el Estado promulgante] después de que haya recibido una solicitud escrita del otorgante si se hubiera producido alguna de las circunstancias descritas en el párrafo 1 del presente artículo y el acreedor asegurado no hubiera cumplido.

3. Si el acreedor asegurado no cumple en el plazo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, el otorgante tendrá derecho a solicitar la cancelación o la correspondiente modificación de la notificación mediante un procedimiento judicial o administrativo sumario.

4. El otorgante tendrá derecho a solicitar la correspondiente modificación o cancelación de la notificación, según proceda, incluso antes de que expire el plazo mencionado en el párrafo 2 del presente artículo, siempre que [existan los debidos mecanismos para proteger al acreedor garantizado].

5. El acreedor asegurado tendrá derecho a inscribir en el registro una notificación de modificación o de cancelación, en la medida que corresponda, con respecto a la notificación pertinente en cualquier momento.

6. Prontamente después de que haya expirado una notificación con arreglo a lo previsto en el artículo 44 o haya sido cancelada con arreglo a lo previsto en los párrafos 1 a 4 del presente artículo, la información consignada en la notificación se retirará del fichero del registro accesible al público.

7. La información facilitada en la noticia expirada, cancelada o enmendada y el hecho de la expiración, cancelación o modificación deberán archivarse durante [un plazo prolongado como, por ejemplo, 20 años, que especificará el Estado promulgante] años de forma que permita la recuperación de la información de conformidad con el artículo [...].

8. En caso de cesión de la obligación garantizada, la notificación podrá modificarse para indicar el nombre del nuevo acreedor garantizado, pero una notificación que no haya sido enmendada de esa forma seguirá siendo eficaz.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que el artículo 47 se basa en las recomendaciones 72 a 75 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas y las recomendaciones 33, 20, y 21 del proyecto de Guía sobre un registro. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar el texto entre corchetes en el párrafo 4, que se basa en la recomendación 72, apartado c) de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas y que, sin alguna explicación, no encaja en una ley modelo. Además, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si los párrafos 5 a 7 deberían presentarse como artículos por separado. Además, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si el proyecto de Ley Modelo debería incluir artículos adicionales para reflejar otras recomendaciones del proyecto de Guía sobre un registro, como, por ejemplo, las recomendaciones sobre notificaciones de modificación y de cancelación, la indexación de información, los criterios de consulta y los resultados de las consultas.]

(A/CN.9/WG.VI/WP.55/Add.3) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de ley modelo sobre las operaciones garantizadas, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23º período de sesiones

ADICIÓN

Índice

Capítulo V.	Prelación de una garantía real
Artículo 48.	Prelación entre garantías reales constituidas por el mismo otorgante sobre el mismo bien gravado
Artículo 49.	Prelación de una garantía real inscrita en un registro especial o anotada en un certificado de titularidad
Artículo 50.	Prelación de los derechos del cesionario o el arrendatario de un bien gravado
Artículo 51.	Prelación de los créditos privilegiados
Artículo 52.	Prelación de los derechos de los acreedores judiciales
Artículo 53.	Prelación de los derechos de personas que presten algún servicio con respecto al bien gravado
Artículo 54.	Prelación de todo derecho reivindicatorio reconocido al proveedor
Artículo 55.	Prelación de una garantía real sobre un bien incorporado a un bien inmueble
Artículo 56.	Prelación de una garantía real sobre un bien incorporado a un bien mueble
Artículo 57.	Prelación de una garantía real sobre una masa de bienes o sobre un producto acabado
Artículo 58.	Incidencia nula sobre la prelación del conocimiento de la existencia de una garantía real
Artículo 59.	Subordinación
Artículo 60.	Consecuencias de la continuidad de la eficacia frente a terceros sobre el orden de prelación
Artículo 61.	Prelación de una garantía real que respalde obligaciones presentes o futuras. .
Artículo 62.	Alcance de la prelación
Artículo 63.	Aplicación de las reglas de prelación a una garantía real sobre un bien futuro.
Artículo 64.	Aplicación de las reglas de prelación a una garantía real sobre el producto . . .
Capítulo VI.	Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía
Artículo 65.	Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía
Artículo 66.	Reglas imperativas

Artículo 67.	Reglas no imperativas
Artículo 68.	Declaraciones del cedente
Artículo 69.	Derecho de notificación del deudor del crédito por cobrar
Artículo 70.	Derecho del cesionario al pago
Capítulo VII.	Derechos y obligaciones del deudor del crédito por cobrar
Artículo 71.	Protección del deudor del crédito por cobrar
Artículo 72.	Notificación de la cesión
Artículo 73.	Pago liberatorio del deudor del crédito por cobrar
Artículo 74.	Excepciones y derechos de compensación del deudor del crédito por cobrar ..
Artículo 75.	Acuerdo de no oponer excepciones ni derechos de compensación
Artículo 76.	Modificación del contrato originario
Artículo 77.	Reintegro de la suma pagada por el deudor del crédito por cobrar
Capítulo VIII.	Ejecución de una garantía real
Artículo 78.	Normas generales de conducta en el contexto de la ejecución
Artículo 79.	Limitaciones de la autonomía de las partes
Artículo 80.	Responsabilidad
Artículo 81.	Recursos judiciales y de otra índole con respecto al incumplimiento
Artículo 82.	Procedimientos judiciales sumarios
Artículo 83.	Derechos del otorgante tras el incumplimiento
Artículo 84.	Extinción de la garantía real tras el pago íntegro de la obligación garantizada
Artículo 85.	Derechos del acreedor garantizado tras el incumplimiento
Artículo 86.	Métodos de ejecución judicial y extrajudicial para ejercer derechos a raíz del incumplimiento
Artículo 87.	Derechos acumulativos posteriores al incumplimiento
Artículo 88.	Derechos que pueden ejercerse a raíz del incumplimiento con respecto a la obligación garantizada
Artículo 89.	Derecho del acreedor garantizado con mayor grado de prelación a hacerse cargo de la ejecución
Artículo 90.	Derecho del acreedor garantizado a la posesión de un bien gravado
Artículo 91.	Obtención por vía extrajudicial de la posesión de bien gravado
Artículo 92.	Enajenación extrajudicial de un bien gravado
Artículo 93.	Notificación anticipada de la enajenación extrajudicial de un bien gravado ..
Artículo 94.	Distribución del producto de la enajenación de un bien gravado
Artículo 95.	Adquisición de un bien gravado como forma de pago de la obligación garantizada

Artículo 96.	Derechos adquiridos mediante enajenación judicial
Artículo 97.	Derechos adquiridos mediante enajenación extrajudicial
Artículo 98.	Concurrencia de regímenes de ejecución relacionados con bienes muebles y bienes inmuebles
Artículo 99.	Ejecución de una garantía real sobre un bien incorporado a un bien inmueble
Artículo 100.	Aplicación del capítulo relativo a la ejecución a las cesiones puras y simples de créditos por cobrar
Artículo 101.	Ejecución de una garantía real sobre un crédito por cobrar
Artículo 102.	Distribución del producto de la enajenación cuando el bien gravado es un crédito por cobrar

Capítulo V. Prelación de una garantía real

Artículo 48. Prelación entre garantías reales constituidas por el mismo otorgante sobre el mismo bien gravado

1. La prelación entre garantías reales concurrentes constituidas por el mismo otorgante sobre el mismo bien gravado se determinará aplicando los siguientes criterios:

a) Entre garantías reales que se hicieron oponibles a terceros mediante la inscripción registral de una notificación, la prelación estará determinada por el orden de inscripción, cualquiera que sea la fecha de constitución de la garantía real;

b) Entre garantías reales que se hicieron oponibles a terceros por algún otro método que no fuera su inscripción registral, la prelación estará determinada por el orden de su oponibilidad a terceros; y

c) Entre una garantía real que se hizo oponible a terceros por inscripción registral y una garantía real que se hizo oponible a terceros por algún otro método, la prelación estará determinada (cualquiera que sea la fecha de constitución) por el orden cronológico de su inscripción o por la fecha de su oponibilidad, de ser esta anterior.

2. El presente artículo está sujeto a las excepciones previstas en los artículos 49 y 55 a 64, así como en los artículos 103 a 111.

Artículo 49. Prelación de una garantía real inscrita en un registro especial o anotada en un certificado de titularidad

1. Una garantía real sobre un bien que pase a ser oponible a terceros por inscripción en un registro especial o por anotación en un certificado de titularidad, conforme a lo previsto en el artículo 23, gozará de prelación sobre:

a) Toda garantía real sobre el mismo bien respecto de la cual se haya inscrito una notificación en el registro general de garantías reales o que se haya hecho oponible a terceros por algún método distinto de la inscripción en un registro especial o de la anotación en un certificado de titularidad, cualquiera que sea la fecha de su oponibilidad; y

b) Toda garantía real que sea subsiguientemente inscrita en el registro especial o anotada en un certificado de titularidad.

2. Si un bien gravado es transmitido o arrendado y, en el momento de la transmisión o arrendamiento, la garantía real sobre ese bien es oponible a terceros por inscripción en un registro especial o por anotación en un certificado de titularidad, conforme a lo previsto en el artículo 23, el cesionario o arrendatario adquirirá los derechos sobre dicho bien sujetos a la garantía real, a reserva de lo previsto en los párrafos 2 a 8 del artículo 50.

3. Si la garantía real no se ha hecho oponible a terceros por inscripción en un registro especial o por anotación en un certificado de titularidad, el cesionario o arrendatario adquirirá sus derechos libres de la garantía real.

Artículo 50. Prelación de los derechos del cesionario o el arrendatario de un bien gravado

1. Si se transfiere o arrienda un bien gravado y una garantía real sobre ese bien es oponible a terceros en el momento de efectuarse la transmisión o arrendamiento, el cesionario o arrendatario adquirirá sus derechos sujetos a la garantía real, a reserva de lo dispuesto en los párrafos 2 a 7 del presente artículo.

2. Un bien gravado dejará de estarlo si el otorgante lo vende o dispone de él de algún otro modo con la autorización del acreedor garantizado de que dicha venta u otro acto de disposición del bien gravado puede efectuarse libre de todo gravamen.

3. Los derechos que adquiera el arrendatario de un bien gravado no se verán afectados por una garantía real si el acreedor garantizado autoriza al otorgante a arrendar o poner bajo licencia ese bien libre de todo gravamen.

4. Un comprador de un bien corporal vendido en el curso normal del negocio del vendedor sin que el comprador, en el momento de la venta, tenga conocimiento de que esa venta se hace en violación de los derechos de un acreedor garantizado a raíz de un acuerdo de garantía, adquirirá el bien libre de todo gravamen.

5. Los derechos de un arrendatario de un bien corporal arrendado en el curso normal del negocio del arrendador, sin conocimiento, en el momento de concertarse el arrendamiento, por parte del arrendatario de que ese arriendo se ha hecho en violación de los derechos del acreedor garantizado previstos en el acuerdo de garantía, no se verán afectados por una garantía real sobre el bien.

6. Si un comprador adquiere un derecho sobre un bien gravado sin quedar sujeto a una garantía real, toda persona que adquiera posteriormente un derecho sobre ese bien del comprador, lo adquirirá también libre de la garantía real.

7. Si los derechos de un arrendatario no se ven afectados por una garantía real, los derechos de todo subarrendatario no se verán tampoco afectados por dicha garantía real.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que el artículo 50 se basa en las recomendaciones 79 a 82 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas y que las referencias a licencias y licenciarios se han suprimido (en este artículo y en otros, como el artículo 49) ya que el proyecto de Ley Modelo no tiene el propósito de ser aplicable a derechos de propiedad intelectual.]

Artículo 51. Prelación de los créditos privilegiados

Solamente los créditos de [cualesquiera créditos específicos limitados que estipule el Estado promulgante] gozarán de prelación frente a una garantía real y solamente hasta un importe de [un importe limitado que estipule el Estado promulgante].

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que el artículo 51 tiene por objeto reflejar el fondo de la recomendación 83 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas.]

Artículo 52. Prelación de los derechos de los acreedores judiciales

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 108, una garantía real gozará de prelación frente a los derechos de un acreedor no garantizado, salvo que el acreedor no garantizado haya obtenido, con arreglo a otra ley, una sentencia o una medida cautelar judicial contra el otorgante y haya adoptado las medidas necesarias para adquirir derechos sobre el bien gravado en razón de la sentencia o la medida cautelar judicial, antes de que la garantía real se hiciera oponible a terceros.

2. La prelación de la garantía real será también aplicable al crédito otorgado por el acreedor garantizado:

a) Antes de la expiración de [un breve plazo, por ejemplo, 30 días, que estipulará el Estado promulgante] días después de que el acreedor no garantizado hubiera notificado al acreedor garantizado que había adoptado las medidas necesarias para adquirir derechos sobre el bien gravado; o

b) De conformidad con un compromiso irrevocable por un importe fijo o por un importe que se haya de fijar con arreglo a una fórmula prescrita por el acreedor garantizado para conceder crédito, si ese compromiso se ha contraído antes de que el acreedor no garantizado hubiera notificado al acreedor garantizado que había adoptado las medidas necesarias para adquirir derechos sobre el bien gravado.

Artículo 53. Prelación de los derechos de personas que presten algún servicio con respecto al bien gravado

Si otra ley aplicable al margen de la presente ley confiere derechos equivalentes a garantías reales a un acreedor que haya prestado servicios respecto de un bien gravado, esos derechos estarán limitados al bien que esté en posesión de ese acreedor hasta un valor razonable de los servicios prestados y gozarán de prelación frente a toda garantía real sobre el bien que haya pasado a ser oponible a terceros por alguno de los métodos mencionados en el artículo 19 o 20.

Artículo 54. Prelación de todo derecho reivindicatorio reconocido al proveedor

Si otra ley aplicable al margen de la presente Ley dispone que el proveedor de bienes corporales tiene un derecho reivindicatorio sobre los mismos, ese derecho reivindicatorio estará subordinado a toda garantía real que se haya hecho oponible a terceros antes de que el proveedor lo ejerciera.

Artículo 55. Prelación de una garantía real sobre un bien incorporado a un bien inmueble

1. Una garantía real o cualquier otro derecho, como el derecho de un comprador o arrendatario, sobre un bien incorporado a un bien inmueble que haya sido constituido y hecho oponible a terceros con arreglo al régimen de la propiedad inmobiliaria, conforme a lo previsto en los artículos 11 y 27, gozará de prelación frente a una garantía real sobre dicho bien incorporado que se haya hecho oponible a terceros por alguno de los métodos mencionados en los artículos 19 o 20.
2. Una garantía real sobre un bien corporal que sea un bien incorporado a un bien inmueble en el momento de hacerse oponible a terceros la garantía o que haya pasado a ser un bien incorporado a un bien inmueble posteriormente, y se haya hecho oponible a terceros por inscripción en el registro de la propiedad inmobiliaria, conforme a lo previsto en el artículo 27, gozará de prelación frente a toda garantía real o cualquier otro derecho, como el derecho de un comprador o de un arrendatario, sobre el bien inmueble conexo que se haya inscrito posteriormente en el registro de la propiedad inmobiliaria.

Artículo 56. Prelación de una garantía real sobre un bien incorporado a un bien mueble

Una garantía real o cualquier otro derecho, como el derecho de un comprador o de un arrendatario, sobre un bien incorporado a un bien mueble que se haga oponible a terceros por inscripción en un registro especial o por anotación en un certificado de titularidad con arreglo a lo previsto en el artículo 26, gozará de prelación sobre toda garantía real u otro derecho sobre el bien mueble conexo que posteriormente se haya inscrito en el registro especial o anotado en el certificado de titularidad.

Artículo 57. Prelación de una garantía real sobre una masa de bienes o sobre un producto acabado

1. Cuando dos o más garantías reales constituidas sobre el mismo bien corporal conserven su validez sobre una masa de bienes o sobre un producto acabado, conforme a lo previsto en el artículo 12, gozarán entre sí de la misma prelación que tuvieran sobre el bien gravado inmediatamente antes de que ese bien pasara a formar parte de la masa de bienes o del producto acabado.
2. Si unas garantías reales constituidas sobre distintos bienes corporales conservan su validez sobre la misma masa de bienes o sobre el producto acabado, y si cada garantía real es oponible a terceros, los acreedores garantizados tendrán derecho a compartir el valor agregado máximo de sus garantías reales sobre la masa de bienes o el producto acabado con arreglo a la relación que existiera entre el valor de sus respectivas garantías reales.
3. Para los fines de la fórmula prevista en el párrafo 2 del presente artículo, el valor máximo de una garantía real será su valor determinado de conformidad con el artículo 12 o el importe de la obligación garantizada, de ser este inferior.
4. Una garantía real para la financiación de adquisiciones constituida sobre un bien corporal originariamente separado que siga siendo válida sobre la masa de bienes o el producto acabado y que sea oponible a terceros, gozará de prelación

frente a una garantía real concedida por el mismo otorgante sobre la masa de bienes o el producto acabado.

Artículo 58. Incidencia nula sobre la prelación del conocimiento de la existencia de una garantía real

El conocimiento por parte del reclamante concurrente de la existencia de una garantía real no afectará al orden de prelación.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que en el comentario se hará referencia a las consecuencias del conocimiento de que una transacción viola los derechos de un acreedor garantizado (véase el artículo 50, párrafos 4 y 5).]

Artículo 59. Subordinación

Un reclamante concurrente que goce de prelación podrá renunciar en cualquier momento a su prelación por medio de un acto unilateral o de un acuerdo a favor de cualquier otro reclamante concurrente existente o futuro.

Artículo 60. Consecuencias de la continuidad de la eficacia frente a terceros sobre el orden de prelación

1. A efectos del artículo 48, la prelación de una garantía real no se verá afectada por algún cambio en el método por el que se haga oponible a terceros, siempre y cuando la garantía real no deje en ningún momento de ser eficaz frente a terceros.
2. Si una garantía real es objeto de una notificación inscrita o se ha hecho oponible a terceros, pero después dejó de estar inscrita o de ser oponible a terceros durante cierto plazo, la prelación de esa garantía real datará, en adelante, a partir de la fecha en que sea subsiguientemente objeto de una notificación inscrita o se haga oponible a terceros, según lo que se produzca en primer lugar.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de tratar la cuestión de la eficacia de notificaciones de modificación y de cancelación que no hayan sido autorizadas por el acreedor asegurado o sean fraudulentas (véase también la nota al artículo 46 en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.55/Add.2 y la nota a la recomendación 19 del proyecto de Guía sobre un registro en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.5).]

Artículo 61. Praelación de una garantía real que respalde obligaciones presentes o futuras

A reserva de lo dispuesto en el artículo 52, la prelación de una garantía real se hará extensiva a todas las obligaciones garantizadas, independientemente del momento en que hayan nacido.

Artículo 62. Alcance de la prelación

[Si el Estado promulgante aplica el artículo 36, apartado d)], la prelación de la garantía real se limitará al importe máximo indicado en la notificación inscrita.

Artículo 63. Aplicación de las reglas de prelación a una garantía real sobre un bien futuro

A los efectos del artículo 48, apartados 1 a) y c), la prelación de una garantía real se hará extensiva a todos los bienes gravados incluidos en la notificación inscrita, con independencia de que esos bienes estén ya adquiridos por el otorgante o de que su existencia date de la propia fecha de inscripción o de antes o después de esa fecha.

Artículo 64. Aplicación de las reglas de prelación a una garantía real sobre el producto

A los efectos del artículo 48, el momento en que una garantía real sobre un bien gravado pase a ser oponible a terceros o el momento en que se inscriba la notificación de esa garantía será también el momento aplicable a la oponibilidad a terceros o a la inscripción de la garantía real subsistente sobre el producto del bien gravado.

Capítulo VI. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía**Artículo 65. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía**

Los derechos y obligaciones mutuos de las partes en un acuerdo de garantía estarán determinados por:

- a) Los términos y condiciones que se enuncien en el acuerdo, incluidas las reglas o condiciones generales a que se haga referencia en dicho acuerdo;
- b) Cualquier uso que hayan convenido; y
- c) A menos que se haya acordado otra cosa, por cualquier práctica que hayan establecido entre ellos.

Artículo 66. Reglas imperativas

1. La parte que esté en posesión de un bien gravado deberá adoptar medidas razonables para preservar dicho bien y conservar su valor.
2. El acreedor garantizado deberá devolver un bien gravado que esté en su posesión cuando, una vez liquidados todos los compromisos de conceder crédito, se haya pagado íntegramente o haya sido satisfecha de alguna otra manera la obligación garantizada y la garantía real haya quedado, por tanto, extinguida.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que el artículo 47 trata de la obligación del acreedor garantizado de inscribir en el registro una notificación de cancelación y considerar si ese asunto debería abordarse en su lugar en el artículo 66 o también en el artículo 66.]

Artículo 67. Reglas no imperativas

A menos que se convenga otra cosa, el acreedor garantizado tendrá derecho:

- a) A que se le reembolsen los gastos razonablemente realizados para preservar un bien gravado que esté en su posesión;
- b) A hacer un uso razonable de un bien gravado que esté en su posesión y a destinar los ingresos que produzca al pago de la obligación garantizada; y
- c) A inspeccionar todo bien gravado que esté en posesión del otorgante.

Artículo 68. Declaraciones del cedente

1. A menos que el cedente y el cesionario hayan acordado otra cosa, el cedente asegurará, en el momento de la celebración del contrato de cesión, que:

- a) El cedente tiene el derecho a ceder el crédito por cobrar;
- b) El cedente no ha cedido con anterioridad el crédito por cobrar a ningún otro cesionario; y
- c) El deudor del crédito por cobrar no puede ni podrá oponer excepciones ni gozar de derechos de compensación.

2. A menos que el cedente y el cesionario hayan convenido otra cosa, el cedente no declarará que el deudor del crédito por cobrar tiene o tendrá la capacidad para pagar.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que en el comentario se aclarará que los artículos 68 a 70 se basan en las recomendaciones 114 a 116 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, que a su vez se basan en los artículos 12 a 14 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos.]

Artículo 69. Derecho de notificación del deudor del crédito por cobrar

1. Salvo que el cedente y el cesionario hayan convenido otra cosa, el cedente o el cesionario, o ambos, podrán enviar al deudor del crédito por cobrar una notificación de la cesión e instrucciones de pago, pero, una vez enviada la notificación, solo el cesionario podrá enviar tales instrucciones.

2. La notificación de la cesión o de las instrucciones de pago efectuada en violación del acuerdo mencionado en el apartado a) del presente artículo no será inválida a efectos del artículo 74 a causa de tal violación.

3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a las obligaciones o a la responsabilidad de la parte que incumpla tal acuerdo en lo que respecta a los daños y perjuicios a que dé lugar dicho incumplimiento.

Artículo 70. Derecho del cesionario al pago

1. Entre el cedente y el cesionario, a menos que se convenga otra cosa, e independientemente de que se haya enviado o no la notificación de la cesión:
 - a) Si el pago del crédito por cobrar cedido se realiza en beneficio del cesionario, este tendrá derecho a retener el producto y los bienes corporales devueltos en relación con el crédito por cobrar cedido.
 - b) Si el pago del crédito por cobrar cedido se realiza en beneficio del cedente, el cesionario tendrá derecho al pago del producto y también a los bienes corporales devueltos al cedente en relación con el crédito por cobrar cedido; y
 - c) Si el pago del crédito por cobrar cedido se hace en beneficio de otra persona respecto de la cual el cesionario goce de prelación, el cesionario tendrá derecho al pago del producto y también a los bienes corporales devueltos a esa persona en relación con el crédito por cobrar cedido.
2. El cesionario no podrá retener un valor superior al de su derecho sobre el crédito por cobrar.

Capítulo VII. Derechos y obligaciones del deudor del crédito por cobrar**Artículo 71. Protección del deudor del crédito por cobrar**

1. De no disponer otra cosa la presente Ley, y sin el consentimiento del deudor del crédito por cobrar, la cesión no afectará a los derechos y obligaciones de este ni a las condiciones de pago estipuladas en el contrato originario.
2. En las instrucciones de pago se podrá cambiar el nombre de la persona, la dirección o la cuenta en la cual el deudor del crédito por cobrar deba efectuar el pago, pero no se podrá cambiar:
 - a) La moneda en que se deba efectuar el pago según el contrato originario; o
 - b) El Estado donde se deba efectuar el pago según el contrato originario por otro que no sea aquel en el que esté situado el deudor del crédito.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que en el comentario se aclarará que los artículos 68 a 70 se basan en las recomendaciones 117 a 123 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, que a su vez se basan en los artículos 15 a 21 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos.]

Artículo 72. Notificación de la cesión

1. Tanto la notificación de la cesión como las instrucciones de pago surtirán efecto una vez recibidas por el deudor del crédito por cobrar si constan en un idioma en el que razonablemente quepa prever que el deudor quedará informado de su contenido. Será suficiente que la notificación de la cesión o las instrucciones de pago consten en el idioma del contrato originario.
2. La notificación de la cesión o las instrucciones de pago podrán corresponder a créditos por cobrar nacidos después de la notificación.

3. La notificación de una cesión subsiguiente constituye notificación de toda cesión anterior.

Artículo 73. Pago liberatorio del deudor del crédito por cobrar

1. Hasta que reciba la notificación de la cesión, el deudor del crédito por cobrar podrá liberarse de su obligación efectuando el pago de conformidad con el contrato originario.
2. Una vez recibida la notificación de la cesión y a reserva de lo dispuesto en los párrafos 3 a 8 del presente artículo, el deudor del crédito por cobrar podrá efectuar el pago liberatorio únicamente en favor del cesionario o de conformidad con las nuevas instrucciones de pago que reciba en la notificación de la cesión o que le dé ulteriormente el cesionario por escrito.
3. Si el deudor del crédito por cobrar recibe más de una instrucción de pago relativa a una única cesión del mismo crédito por cobrar efectuada por el mismo cedente, quedará liberado de su obligación efectuando el pago de conformidad con las últimas instrucciones de pago que hubiera recibido del cesionario antes de hacerlo.
4. Si el deudor del crédito recibe notificación de más de una cesión del mismo crédito por cobrar efectuada por el mismo cedente, quedará liberado de su obligación efectuando el pago de conformidad con la primera notificación que reciba.
5. Si el deudor del crédito por cobrar recibe notificación de una o más cesiones subsiguientes, quedará liberado de su obligación efectuando el pago de conformidad con la notificación de la última de las cesiones subsiguientes.
6. Si el deudor del crédito por cobrar recibe notificación de la cesión de una parte de uno o más créditos por cobrar o de un derecho indiviso sobre tales créditos, quedará liberado de su obligación pagando de conformidad con la notificación o de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo como si no hubiera recibido la notificación.
7. Si el deudor del crédito por cobrar recibe una notificación con arreglo a lo previsto en el párrafo 6 del presente artículo y paga de conformidad con la notificación, solo quedará liberado de su obligación en lo que respecta a la parte o al derecho indiviso pagado.
8. Si el deudor del crédito por cobrar recibe notificación de la cesión por el cesionario, tendrá derecho a pedirle que presente en un plazo razonable prueba suficiente de que la cesión del cedente inicial al cesionario inicial y todas las cesiones intermedias han tenido lugar y, de no hacerlo el cesionario, el deudor del crédito por cobrar quedará liberado de su obligación efectuando el pago de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo como si no hubiera recibido la notificación del cesionario.
9. Por prueba suficiente de una cesión mencionada en el párrafo 8 del presente artículo se entenderá cualquier escrito emanante del cedente, o cualquier prueba equivalente, en que se indique que la cesión ha tenido lugar.
10. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier otro motivo por el cual el deudor del crédito por cobrar quede liberado de su

obligación efectuando el pago a quien tenga derecho a percibirlo, a una autoridad judicial competente o a otra autoridad, o a una caja pública de depósitos.

Artículo 74. Excepciones y derechos de compensación del deudor del crédito por cobrar

1. El deudor del crédito, frente a la acción del cesionario para reclamarle el pago de los créditos por cobrar cedidos, podrá oponer las excepciones o los derechos de compensación derivados del contrato originario, o de cualquier otro contrato que fuera parte de la misma operación, que tendría si la cesión no hubiera tenido lugar y si la acción hubiese sido ejercida por el cedente.
2. El deudor del crédito por cobrar podrá oponer al cesionario cualquier otro derecho de compensación, siempre que lo hubiera podido invocar en el momento de recibir la notificación de la cesión.
3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el deudor del crédito por cobrar no podrá oponer al cesionario las excepciones y los derechos de compensación que tenga contra el cedente de conformidad con el artículo 14, párrafo 2 o el artículo 15, párrafo 5, en razón del incumplimiento de un acuerdo por el que se limite de alguna manera el derecho del cedente a efectuar la cesión.

Artículo 75. Acuerdo de no oponer excepciones ni derechos de compensación

1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo, el deudor de un crédito por cobrar, mediante escrito firmado por él, podrá convenir con el cedente en no oponer al cesionario las excepciones y los derechos de compensación que tenga en virtud del artículo 74.
2. Un acuerdo concertado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, que se podrá modificar únicamente por un acuerdo por escrito firmado por el deudor del crédito por cobrar y cuyo efecto frente al cesionario viene determinado por el artículo 76, párrafo 2, impedirá al deudor del crédito por cobrar oponer al cesionario las excepciones y derechos de compensación previstos en el párrafo 1 del presente artículo.
3. El deudor del crédito por cobrar no podrá renunciar a oponer excepciones derivadas de actos fraudulentos imputables al cesionario ni basadas en su propia incapacidad.

Artículo 76. Modificación del contrato originario

1. Un acuerdo concertado antes de la notificación de la cesión entre el cedente y el deudor del crédito por cobrar que afecte a los derechos del cesionario será válido respecto de este, el cual adquirirá los derechos correspondientes.
2. Un acuerdo concertado después de la notificación de la cesión entre el cedente y el deudor del crédito por cobrar que afecte a los derechos del cesionario no será válido respecto de este salvo si:
 - a) El cesionario consiente en él; o
 - b) El crédito no es completamente exigible por la falta de pleno cumplimiento del contrato originario y, o bien este prevé la modificación, o

cualquier cesionario razonable consentiría en tal modificación en el contexto de dicho contrato.

3. Lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del presente artículo no afectará a los derechos del cedente o del cesionario en razón del incumplimiento de un acuerdo concertado entre ellos.

Artículo 77. Reintegro de la suma pagada por el deudor del crédito por cobrar

1. El incumplimiento por el cedente del contrato originario no dará derecho al deudor del crédito a recuperar del cesionario la suma que hubiese pagado al cedente o al cesionario.

2. Lo anteriormente dispuesto no afecta a los derechos que el deudor del crédito por cobrar pueda tener frente al cedente.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que el artículo 77 se basa en la recomendación 123 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, que a su vez se basa en el artículo 21 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos. Se ha añadido el párrafo 2 para aclarar que el objetivo de este artículo no es privar al deudor del crédito por cobrar de cualesquiera derechos que pudiera tener en virtud de otra ley aplicable para pedir el reembolso de los pagos de su socio contractual, es decir, el cedente.]

Capítulo VIII. Ejecución de una garantía real

Artículo 78. Normas generales de conducta en el contexto de la ejecución

Todas las partes deberán ejecutar sus derechos y cumplir sus obligaciones conforme a las disposiciones sobre la ejecución, actuando de buena fe y de forma razonable desde el punto de vista mercantil.

Artículo 79. Limitaciones de la autonomía de las partes

1. Las normas generales de conducta previstas en el artículo 78 no podrán ser objeto de una renuncia unilateral ni modificarse mediante acuerdo en ningún momento.

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo:

a) El otorgante y las demás personas que adeuden un pago o que deban cumplir una obligación garantizada podrán renunciar unilateralmente a cualquiera de los derechos que le confieren las disposiciones relativas a la ejecución o modificarlos mediante acuerdo, pero únicamente cuando haya habido incumplimiento; y

b) El acreedor garantizado podrá renunciar unilateralmente a cualquiera de los derechos que le confieren las disposiciones relativas a la ejecución o modificarlos mediante acuerdo.

3. Una modificación de los derechos mediante acuerdo no afectará a los derechos de una persona que no sea parte en el acuerdo.

4. La carga de la prueba recaerá en la persona que impugne la validez del acuerdo argumentando que es incompatible con los párrafos 1, 2, 3 o 4 del presente artículo.

Artículo 80. Responsabilidad

Si una persona incumple las obligaciones establecidas en las disposiciones relativas a la ejecución, estará sujeta al pago de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.

Artículo 81. Recursos judiciales y de otra índole con respecto al incumplimiento

El deudor, el otorgante u otras personas interesadas tendrán derecho a recurrir en cualquier momento a un tribunal o a otra autoridad en caso de que el acreedor garantizado no cumpla con sus obligaciones previstas en las disposiciones relativas a la ejecución.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que, a los efectos de este y otros artículos (por ejemplo, el artículo 84), en el comentario se presentarán ejemplos de personas interesadas, por ejemplo, un acreedor garantizado con un grado de prelación inferior al del acreedor garantizado ejecutante, un garante o un copropietario de los bienes gravados.]

Artículo 82. Procedimientos judiciales sumarios

Cuando el acreedor garantizado, el otorgante u otra persona que deba cumplir la obligación garantizada o que pretenda tener algún derecho sobre un bien gravado recurra a un tribunal o a otra autoridad en relación con el ejercicio de los derechos que tiene a raíz del incumplimiento, las actuaciones deberían llevarse a cabo de una forma relativamente expeditiva.

[Nota para el Grupo de Trabajo: Si el Grupo de Trabajo decide retener la expresión “de una forma razonablemente expeditiva”, tal vez desee aclararla más a fondo en este artículo o en el comentario pertinente. De otra forma, el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de revisar la formulación de este artículo.]

Artículo 83. Derechos del otorgante tras el incumplimiento

Al producirse el incumplimiento, el otorgante tendrá derecho a ejercer uno o más de los siguientes derechos:

- a) Pagar íntegramente la obligación garantizada y quedar liberado de la garantía real constituida sobre todos los bienes gravados que respalden la obligación, conforme a lo previsto en el artículo 84;
- b) Apelar ante un tribunal u otra autoridad en caso de que el acreedor garantizado no esté cumpliendo sus obligaciones previstas en las disposiciones de la presente Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 81;
- c) Proponer al acreedor garantizado, o rechazar la propuesta de este, de aceptar un bien gravado a modo de satisfacción total o parcial de la obligación garantizada, conforme a lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo 95; y

d) Ejercer cualquier otro derecho previsto en el acuerdo de garantía o en otra regla de derecho.

Artículo 84. Extinción de la garantía real tras el pago íntegro de la obligación garantizada

1. El deudor, el otorgante u otra persona interesada tendrán derecho a pagar íntegramente la obligación garantizada, incluidos los gastos de ejecución hasta el momento del pago íntegro.
2. Ese derecho se podrá ejercer hasta que el acreedor garantizado enajene o acepte el bien gravado o cobre su importe o hasta que el acreedor garantizado celebre un acuerdo para enajenar el bien gravado, de ocurrir esto primero.
3. Si se han cancelado todos los compromisos de otorgar crédito financiero, con este pago todos los bienes gravados que respaldan esa obligación dejarán de estar sujetos a la garantía real, a reserva de todo derecho de subrogación en beneficio de la persona que efectúa el pago.

Artículo 85. Derechos del acreedor garantizado tras el incumplimiento

Tras el incumplimiento, el acreedor garantizado tendrá derecho a ejercer uno o más de los siguientes derechos con respecto a un bien gravado:

- a) Obtener la posesión de un bien corporal gravado, conforme a lo dispuesto en los artículos 90 y 91;
- b) Vender o enajenar de algún otro modo un bien gravado, arrendarlo o conceder una licencia respecto de él, conforme a los artículos 92 y 93;
- c) Proponer al otorgante que el acreedor garantizado acepte un bien gravado a modo de cumplimiento total o parcial de la obligación garantizada, conforme al artículo 95;
- d) Ejecutar su garantía real sobre un bien incorporado, conforme al artículo 99;
- e) Cobrar el valor o ejecutar de otro modo una garantía real sobre un bien gravado que sea un crédito por cobrar, conforme al artículo 101; y
- f) Ejercer cualquier otro derecho previsto en el acuerdo de garantía (excepto si es incompatible con las disposiciones de la presente Ley) o en cualquier regla de derecho.

Artículo 86. Métodos de ejecución judicial y extrajudicial para ejercer derechos a raíz del incumplimiento

1. Tras un incumplimiento, el acreedor garantizado podrá ejercer los derechos previstos en el artículo 85 recurriendo a un tribunal o a otra autoridad, o sin tener que interponer ese tipo de recurso.
2. El ejercicio de los derechos del acreedor garantizado por vía extrajudicial está supeditado a lo establecido en la norma general de conducta enunciada en el artículo 78 y a los requisitos establecidos en los artículos 91 a 93 en lo que respecta a la obtención extrajudicial de la posesión y la enajenación de un bien gravado.

Artículo 87. Derechos acumulativos posteriores al incumplimiento

El ejercicio de un derecho tras el incumplimiento no invalidará la posibilidad de acogerse a otro derecho, salvo que el ejercicio de un derecho haya hecho imposible ejercer otro derecho.

Artículo 88. Derechos que pueden ejercerse a raíz del incumplimiento con respecto a la obligación garantizada

El ejercicio de los derechos posteriores al incumplimiento con respecto a un bien gravado no invalidarán la posibilidad de ejercer derechos posteriores al incumplimiento con respecto a la obligación garantizada por dicho bien gravado, y viceversa.

Artículo 89. Derecho del acreedor garantizado con mayor grado de prelación a hacerse cargo de la ejecución

1. Cuando un acreedor garantizado haya iniciado la ejecución adoptando alguna de las medidas descritas en las disposiciones relativas a la ejecución o un acreedor judicial haya adoptado las medidas enunciadas en el artículo 52, el acreedor garantizado cuya garantía real goce de prelación sobre la del acreedor garantizado ejecutante o sobre la del acreedor judicial ejecutante tendrá derecho a encargarse del proceso de ejecución en cualquier momento anterior a la enajenación final, a la aceptación o al cobro de un bien gravado o a la celebración de un acuerdo por parte del acreedor garantizado para enajenar el bien gravado, de ocurrir esto primero.
2. El derecho a encargarse de la ejecución incluye el de proceder a la ejecución mediante cualquier método previsto en los artículos 78 a 102.

Artículo 90. Derecho del acreedor garantizado a la posesión de un bien gravado

Al producirse un incumplimiento, el acreedor garantizado tendrá derecho a la posesión de un bien corporal gravado.

Artículo 91. Obtención por vía extrajudicial de la posesión de bien gravado

El acreedor garantizado podrá optar por obtener la posesión de un bien gravado corporal sin recurrir a un tribunal o a otra autoridad únicamente en los siguientes casos:

- a) Si el otorgante ha dado su consentimiento, en el acuerdo de garantía, a que el acreedor garantizado pueda obtener la posesión sin recurrir a un tribunal o a otra autoridad;
- b) Si el acreedor garantizado ha notificado al otorgante y a cualquier persona que esté en posesión del bien gravado el incumplimiento y la intención del acreedor garantizado de obtener la posesión sin recurrir a un tribunal o a otra autoridad; y

c) Si en el momento en que el acreedor garantizado trate de obtener la posesión del bien gravado, el otorgante y cualquier persona que esté en posesión de dicho bien no pongan ningún reparo.

Artículo 92. Enajenación extrajudicial de un bien gravado

1. Tras producirse un incumplimiento, el acreedor garantizado tendrá derecho, sin recurrir a ningún tribunal ni a otra autoridad, a vender o a enajenar de otro modo un bien gravado o a arrendarlo, hasta donde corresponda a los derechos que el otorgante tenga sobre el bien gravado.

2. A reserva de la norma de conducta prevista en el artículo 78, un acreedor garantizado que opte por ejercer ese derecho podrá elegir el método, la manera, el momento, el lugar y otros aspectos de la enajenación o el arrendamiento.

Artículo 93. Notificación anticipada de la enajenación extrajudicial de un bien gravado

1. Tras producirse un incumplimiento, el acreedor garantizado deberá dar notificación de su intención de proceder a la venta o a otro tipo de enajenación de un bien gravado, a su arrendamiento o a la concesión de una licencia sobre él, sin recurrir a ningún tribunal ni a otra autoridad.

2. No será preciso efectuar la notificación si el bien gravado es un bien perecedero, si puede perder valor rápidamente o si es un tipo de bien que se pueda vender en un mercado reconocido.

3. La notificación deberá efectuarse de forma eficiente, oportuna y fiable, a fin de proteger al otorgante o a otras partes interesadas, evitando al mismo tiempo toda repercusión negativa en los recursos del acreedor garantizado y en el valor potencial neto de liquidación de los bienes gravados.

4. La notificación deberá darse:

a) Al otorgante, al deudor y a cualquier otra persona que adeude el pago de la obligación garantizada;

b) A cualquier persona que tenga derechos sobre el bien gravado y que, más de [se especificará el número] días antes de que el acreedor garantizado haya notificado al otorgante, haya dado a conocer por escrito esos derechos al acreedor garantizado;

c) A cualquier otro acreedor garantizado que, más de [se especificará un breve plazo] días antes de que se envíe la notificación al otorgante, haya registrado una notificación de garantía real sobre el bien gravado que quede indexada bajo el identificador del otorgante; y

d) A cualquier otro acreedor garantizado que haya estado en posesión del bien gravado cuando el acreedor garantizado ejecutante tomó posesión de dicho bien.

5. La notificación deberá efectuarse por escrito al menos [un breve plazo, como 15 días, que estipulará el Estado promulgante] días antes de que se efectúe la enajenación extrajudicial y deberá contener un cálculo del importe adeudado en ese momento y una indicación del derecho del deudor o del otorgante a obtener que los

bienes gravados queden liberados de la garantía real con arreglo a lo previsto en el artículo 84.

6. La notificación se redactará en un idioma que quepa razonablemente prever que será entendido por los destinatarios, de modo que queden informados de su contenido. Bastará que la notificación al otorgante se dé en el idioma del acuerdo de garantía que se esté ejecutando.

Artículo 94. Distribución del producto de la enajenación de un bien gravado

1. En caso de enajenación extrajudicial de un bien gravado:

a) El acreedor garantizado ejecutante deberá destinar el producto neto de su ejecución, previa deducción de los costos de ejecución, al pago de la obligación garantizada;

b) A reserva de lo previsto en el apartado 1 c) del presente artículo, el acreedor garantizado ejecutante deberá cancelar todo superávit que subsista tras este pago a los demandantes concurrentes subordinados que, antes de toda distribución del superávit, hayan notificado al acreedor garantizado ejecutante su reclamación concurrente subordinada, hasta por el importe que corresponda a su reclamación, y el saldo restante, si lo hubiere, deberá remitirse al otorgante; y

c) Exista o no controversia sobre el derecho de algún reclamante concurrente a cobrar o sobre el grado de prelación en el cobro con arreglo a la presente Ley, el acreedor garantizado ejecutante podrá, de conformidad con las reglas procesales generalmente aplicables, hacer efectivo el superávit a una autoridad judicial competente u otra autoridad o a una caja pública de depósitos para su distribución.

2. La distribución del producto resultante de una liquidación judicial o de otro procedimiento de ejecución administrado oficialmente deberá efectuarse conforme a [las normas generales del Estado promulgante que rijan los procedimientos de ejecución], pero con sujeción a las reglas de prelación de la presente Ley.

3. El deudor y toda otra persona que adeude el pago de la obligación garantizada deberán abonar todo déficit en el saldo pagado que quede pendiente tras la aplicación del producto neto de la ejecución al cumplimiento de la obligación garantizada.

Artículo 95. Adquisición de un bien gravado como forma de pago de la obligación garantizada

1. Al producirse un incumplimiento, el acreedor garantizado podrá proponer por escrito que recibiría uno o más de los bienes gravados a modo de pago total o parcial de la obligación garantizada.

2. La propuesta deberá enviarse:

a) Al otorgante, al deudor y a cualquier otra persona que adeude pagos correspondientes a la obligación garantizada o deba cumplirla, incluido un garante;

b) A toda persona a la que asistan derechos sobre el bien gravado que haya notificado esos derechos por escrito al acreedor garantizado más de [un breve plazo,

por ejemplo, 15 días, que estipulará el Estado promulgante] días antes del envío de la propuesta por parte del acreedor garantizado al otorgante;

c) A cualquier otro acreedor garantizado que, más de [el Estado promulgante estipulará un breve plazo, por ejemplo, 15 días] antes de que la propuesta sea enviada por el acreedor garantizado al otorgante, haya inscrito en un registro una notificación de una garantía real sobre el bien gravado indexado bajo el identificador del otorgante; y

d) A cualquier otro acreedor garantizado que se halle en posesión del bien gravado en el momento en que se hubiera hecho cargo de él el acreedor garantizado.

3. En la propuesta deberá especificarse el importe adeudado en la fecha en que se envió la propuesta, así como la cuantía de la obligación que se propone dar por satisfecha al aceptar el bien gravado.

4. El acreedor garantizado podrá hacerse cargo del bien gravado, de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 del presente artículo, a menos que reciba de una persona que tenga derecho a que se le envíe dicha propuesta una objeción por escrito dentro de [un breve plazo, por ejemplo, 15 días, que estipulará el Estado promulgante] días a partir de la fecha de envío de la propuesta.

5. En caso de una propuesta de aceptación del bien gravado como pago parcial de la obligación garantizada, será necesario el consentimiento afirmativo por parte de cada destinatario de la propuesta.

6. El otorgante podrá formular una propuesta de esa índole y si el acreedor garantizado la acepta, el acreedor garantizado deberá proceder conforme a lo dispuesto en los párrafos 2 a 5 del presente artículo.

Artículo 96. Derechos adquiridos mediante enajenación judicial

Si un acreedor garantizado enajena un bien gravado mediante un procedimiento judicial u otro procedimiento administrado oficialmente, los derechos adquiridos por el cesionario se determinarán conforme a [las normas generales del Estado promulgante que rijan los procedimientos de ejecución].

Artículo 97. Derechos adquiridos mediante enajenación extrajudicial

1. Si un acreedor garantizado vende o enajena de otra manera un bien gravado sin recurrir a un tribunal ni a otra autoridad, de conformidad con la presente Ley, una persona que adquiera el derecho del otorgante sobre el bien estará sujeta a los derechos que tengan mayor grado de prelación sobre la garantía real del acreedor garantizado ejecutante, pero estará libre de los derechos del acreedor garantizado ejecutante y de los de otra parte reclamante concurrente cuyo grado de prelación sea inferior al del acreedor garantizado ejecutante.

2. La regla prevista en el párrafo 1 del presente artículo se aplicará a los derechos sobre un bien gravado adquirido por un acreedor garantizado que haya recibido el bien gravado como pago total o parcial de la obligación garantizada.

3. Si un acreedor garantizado arrienda un bien gravado sin recurrir a un tribunal ni a otra autoridad, de conformidad con la presente Ley, el arrendatario adquirirá el beneficio del arriendo durante el período correspondiente, a reserva de los derechos que tuvieran prelación sobre la garantía real del acreedor garantizado ejecutante.

4. Si el acreedor garantizado vende o enajena de otro modo, o arrienda, el bien gravado de manera no conforme a lo dispuesto en los artículos 78 a 102, todo adquirente o arrendatario del bien gravado que actúe de buena fe adquirirá los derechos o beneficios descritos en el artículo 97.

Artículo 98. Concurrencia de regímenes de ejecución relacionados con bienes muebles y bienes inmuebles

1. El acreedor garantizado podrá optar por ejecutar una garantía real sobre un bien incorporado a un bien inmueble con arreglo a lo dispuesto en los artículos 78 a 102 o [de conformidad con el régimen del Estado promulgante que rija la ejecución de gravámenes sobre bienes inmuebles].
2. Si una obligación está respaldada tanto por un bien mueble como por un bien inmueble de un otorgante, el acreedor garantizado podrá optar por ejecutar:
 - a) La garantía real sobre el bien mueble conforme a las disposiciones de la presente Ley sobre la ejecución de una garantía real sobre un bien mueble y el gravamen sobre el bien inmueble de conformidad con [la ley del Estado promulgante que rija la ejecución de gravámenes sobre bienes inmuebles]; o
 - b) Ambas garantías reales conforme a [la ley del Estado promulgante que rija la ejecución de gravámenes sobre bienes inmuebles].

Artículo 99. Ejecución de una garantía real sobre un bien incorporado a un bien inmueble

1. Un acreedor garantizado que tenga una garantía real sobre un bien incorporado a un bien inmueble solo tendrá derecho a ejecutar su garantía real si goza de prelación respecto de los derechos concurrentes sobre el bien inmueble.
2. Un acreedor que tenga un derecho concurrente sobre el bien inmueble con un grado de prelación inferior al de la garantía real del acreedor garantizado ejecutante tendrá derecho a liquidar la obligación respaldada por una garantía real del acreedor garantizado ejecutante sobre el bien incorporado.
3. El acreedor garantizado ejecutante será responsable de los daños sufridos por el bien inmueble al separar de él el bien incorporado, pero no de ninguna pérdida de valor que se deba únicamente a la ausencia del bien incorporado.
4. Un acreedor garantizado que tenga una garantía real sobre un bien incorporado a un bien mueble tendrá derecho a ejecutar su garantía real sobre el bien incorporado.
5. El acreedor que tenga un derecho concurrente sobre el bien mueble que goce de un grado de prelación más alto que la garantía real del acreedor garantizado ejecutante tendrá derecho a hacerse cargo del procedimiento de ejecución, con arreglo a lo previsto en el artículo 89.
6. El acreedor que tenga un derecho concurrente sobre el bien mueble que goce de un grado de prelación inferior al de la garantía real del acreedor garantizado ejecutante tendrá derecho a liquidar la obligación respaldada por la garantía real del acreedor garantizado ejecutante sobre el bien incorporado.

7. El acreedor garantizado ejecutante será responsable de los daños sufridos por el bien mueble al separar de él el bien incorporado, pero no de la pérdida de valor que se deba únicamente a la ausencia del bien incorporado.

Artículo 100. Aplicación del capítulo relativo a la ejecución a las cesiones puras y simples de créditos por cobrar

Los artículos 78 a 102 no se aplicarán al cobro u otra ejecución de un crédito por cobrar cedido mediante cesión pura y simple, exceptuando:

- a) Los artículos 78 y 79 en el caso de una cesión pura y simple con recurso; y
- b) El artículo 101.

Artículo 101. Ejecución de una garantía real sobre un crédito por cobrar

- 1. En el caso de un crédito por cobrar transferido mediante una cesión pura y simple, a reserva de lo dispuesto en los artículos 71 a 77, el cesionario tendrá el derecho a cobrar o a hacer ejecutar de algún otro modo el crédito por cobrar.
- 2. En el caso de un crédito por cobrar no transferido mediante una cesión pura y simple, el cesionario tendrá el derecho, a reserva de lo dispuesto en los artículos 71 a 77, a cobrar o a hacer ejecutar de algún otro modo el crédito por cobrar después del incumplimiento, o antes del incumplimiento con el acuerdo del cedente.
- 3. El derecho del cesionario a cobrar o a hacer ejecutar de otro modo un crédito por cobrar incluye el derecho a cobrar o a hacer ejecutar de otro modo cualquier derecho personal o real que respalde el pago del crédito por cobrar.

Artículo 102. Distribución del producto de la enajenación cuando el bien gravado es un crédito por cobrar

- 1. En caso de cobro u otro modo de ejecución de un crédito por cobrar, el acreedor garantizado ejecutante deberá aplicar el producto neto de su ejecución, previa deducción de los gastos de ejecución, a la obligación garantizada.
- 2. El acreedor garantizado ejecutante deberá abonar todo superávit restante a los reclamantes concurrentes que, antes de la distribución del superávit, hayan notificado al acreedor garantizado ejecutante el importe de su reclamación concurrente, en la medida de esa reclamación, y el saldo restante, de haberlo, deberá remitirse al otorgante.

(A/CN.9/WG.VI/WP.55/Add.4) (Original: inglés)

Nota de la Secretaría sobre el proyecto de ley modelo sobre las operaciones garantizadas, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23º período de sesiones

ADICIÓN

Índice

Capítulo IX. Financiación garantizada de adquisiciones	
Variante A: Enfoque unitario	
Artículo 103. Equivalencia entre una garantía real del pago de una adquisición y una garantía real en general	
Artículo 104. Oponibilidad y prelación de una garantía real del pago de bienes de consumo	
Artículo 105. Prelación de las garantías reales del pago de bienes corporales	
Artículo 106. Prelación de una garantía real inscrita en un registro especial o anotada en un certificado de titularidad	
Artículo 107. Prelación entre garantías reales del pago de una adquisición concurrentes	
Artículo 108. Prelación de una garantía real del pago de una adquisición frente al derecho de un acreedor judicial	
Artículo 109. Prelación de una garantía real del pago de una adquisición sobre un bien fijo o incorporado a un inmueble frente a todo gravamen anteriormente inscrito sobre dicho inmueble	
Artículo 110. Prelación de una garantía real del pago de una adquisición sobre el producto de un bien corporal	
Artículo 111. Las garantías reales del pago de una adquisición como garantías reales en el procedimiento de insolvencia	
Variante B: Enfoque no unitario	
Artículo 112. Métodos de financiación de las adquisiciones	
Artículo 113. Equivalencia entre un derecho de retención de la titularidad y un derecho de arrendamiento financiero y una garantía real del pago de una adquisición.	
Artículo 114. Eficacia jurídica de un derecho de retención de la titularidad y de un derecho de arrendamiento financiero	
Artículo 115. Derecho del comprador o del arrendatario a constituir una garantía real	
Artículo 116. Oponibilidad a terceros de un derecho de retención de la titularidad o de un derecho de arrendamiento financiero sobre bienes de consumo	
Artículo 117. Oponibilidad a terceros de un derecho de retención de la titularidad sobre un bien corporal	
Artículo 118. Suficiencia de una sola notificación.	

Artículo 119.	Consecuencias de que no se obtenga la oponibilidad a terceros de un derecho de retención de la titularidad o de un derecho de arrendamiento financiero.
Artículo 120.	Oponibilidad a terceros del derecho de retención de la titularidad o del derecho de arrendamiento financiero sobre un bien incorporado a un bien inmueble
Artículo 121.	Existencia de una garantía real sobre el producto de bienes corporales objeto de un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero
Artículo 122.	Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre el producto de un bien corporal objeto de un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero.
Artículo 123.	Prelación de una garantía real sobre el producto de un bien corporal.
Artículo 124.	Ejecución de un derecho de retención de la titularidad o de un derecho de arrendamiento financiero
Artículo 125.	Ley aplicable a un derecho de retención de la titularidad o a un derecho de arrendamiento financiero
Artículo 126.	Derecho de retención de la titularidad o derecho de arrendamiento financiero en un procedimiento de insolvencia
Capítulo X.	Conflicto de leyes.
Artículo 127.	Ley aplicable a las garantías reales sobre bienes corporales
Artículo 128.	Ley aplicable a las garantías reales sobre bienes corporales en tránsito o destinados a la exportación.
Artículo 129.	Ley aplicable a las garantías reales sobre bienes inmateriales
Artículo 130.	Ley aplicable a una garantía real sobre créditos por cobrar nacidos de una venta, de un arrendamiento o de una operación respaldada por un acuerdo de garantía relativo a un bien inmueble
Artículo 131.	Ley aplicable a la oponibilidad a terceros de garantías reales sobre determinados tipos de bienes mediante inscripción registral
Artículo 132.	Ley aplicable a las garantías reales sobre el producto de un bien.
Artículo 133.	Ley aplicable a los derechos y obligaciones del otorgante y del acreedor garantizado
Artículo 134.	Ley aplicable a los derechos y obligaciones de los terceros deudores y los acreedores garantizados
Artículo 135.	Ley aplicable a la ejecución de una garantía real
Artículo 136.	Significado de la “ubicación” del otorgante.
Artículo 137.	Momento aplicable al determinar la ubicación.
Artículo 138.	Exclusión de la remisión
Artículo 139.	Orden público y reglas imperativas de alcance internacional.

Artículo 140.	Efecto de la apertura de un procedimiento de insolvencia en la ley aplicable a las garantías reales
Artículo 141.	Reglas especiales para situaciones en que el derecho aplicable sea el de un Estado con varias unidades territoriales
Capítulo XI.	Disposiciones transitorias
Artículo 142.	Fecha de entrada en vigor
Artículo 143.	Inaplicabilidad de la ley a las actuaciones abiertas antes de su entrada en vigor
Artículo 144.	Constitución de una garantía real
Artículo 145.	Oponibilidad a terceros de una garantía real
Artículo 146.	Prelación de una garantía real

Capítulo IX. Financiación garantizada de adquisiciones

Variante A: Enfoque unitario*

Artículo 103: Equivalencia entre una garantía real del pago de una adquisición y una garantía real en general

Toda garantía real del pago de una adquisición constituye una garantía real, por lo que todos los artículos que rigen las garantías reales, inclusive los relativos a su constitución, oponibilidad a terceros, inscripción registral, prelación (a reserva de lo dispuesto en los artículos 105 a 110), ejecutoriedad y derecho aplicable a una garantía real, se aplican a las garantías reales del pago de una adquisición.

Artículo 104. Oponibilidad y prelación de una garantía real del pago de bienes de consumo

Toda garantía real del pago de bienes de consumo es oponible a terceros a raíz de su constitución y, a reserva de lo dispuesto en el artículo 106, gozará de prelación sobre una garantía real concurrente sin fines de adquisición constituida por el otorgante.

Artículo 105. Prelación de las garantías reales del pago de bienes corporales

A reserva de lo dispuesto en el artículo 106:

Variante A**

a) Toda garantía real del pago de un bien corporal, que no sea un bien de consumo ni forme parte de existencias, gozará de prelación frente a toda garantía

* Un Estado podrá adoptar la variante A (enfoque unitario), es decir, los artículos 103 a 111, o la variante B (enfoque no unitario), es decir, los artículos 112 a 126. Los artículos que no figuran en el presente capítulo son aplicables de forma general, salvo en la medida en que hayan sido modificados por los artículos de este capítulo.

** Los Estados podrán adoptar la variante A o la variante B del artículo 105.

concurrente constituida por el otorgante para fines que no sean garantizar el pago (aun cuando se haya inscrito una notificación de dicha garantía en el registro general de las garantías reales antes que la notificación concerniente a la garantía del pago de su adquisición), siempre y cuando:

- i) El acreedor garantizado por la garantía de adquisición retenga la posesión del bien corporal; o
 - ii) Se inscriba una notificación de la garantía real del pago en el registro general de las garantías reales en un plazo de [un breve plazo, por ejemplo de 30 días, que fijará el Estado promulgante] días a partir de la entrega del bien corporal gravado al otorgante;
- b) Una garantía real del pago de existencias gozará de prelación frente a toda garantía real concurrente sin fines de adquisición constituida por el otorgante (aun cuando la segunda haya pasado a ser oponible a terceros antes que la primera), siempre y cuando:
- i) El acreedor garantizado que haya financiado la adquisición retenga la posesión de las existencias; o
 - ii) Antes de la entrega de las existencias al otorgante:
 - a. Se haya inscrito una notificación de la garantía real del pago de su adquisición en el registro general de las garantías reales; y
 - b. El acreedor garantizado que financie la adquisición notifique al acreedor garantizado de la garantía sin fines de adquisición antes inscrita, constituida por el otorgante sobre existencias de la misma índole, que tiene una garantía real del pago de una adquisición o que pretende obtenerla.
 - iii) En la notificación mencionada en el apartado b) ii) b. del presente artículo se describan las existencias con suficiente claridad para que el acreedor garantizado de la garantía real sin fines de adquisición pueda individualizar las existencias que son objeto de la garantía real del pago de una adquisición;
- c) Una única notificación, efectuada con arreglo al apartado b) ii) b. del presente artículo, podrá abarcar garantías reales del pago de una adquisición en el marco de operaciones múltiples entre las mismas partes sin necesidad de precisar en ella cada una de esas operaciones, y será válida únicamente para las garantías reales del pago de los bienes corporales cuya posesión obtenga el otorgante en un plazo de [por ejemplo, cinco años, que fijará el Estado promulgante] años a partir de la fecha de la notificación.

Variante B

Toda garantía real del pago de un bien corporal, que no sea un bien de consumo, gozará de prelación frente a una garantía concurrente constituida por el otorgante para fines que no sean garantizar el pago (aun cuando se haya inscrito una notificación de dicha garantía en el registro general de las garantías reales antes que la notificación referente a la garantía del pago de su adquisición), siempre y cuando:

- a) El acreedor garantizado por la garantía de adquisición retenga la posesión del bien corporal; o

b) Se inscriba una notificación de la garantía real del pago en el registro general de las garantías reales en un plazo de [un plazo breve, por ejemplo, de 30 días, que fijará el Estado promulgante] a partir de la entrega del bien corporal al otorgante.

Artículo 106. Prelación de una garantía real inscrita en un registro especial o anotada en un certificado de titularidad

La prelación de una garantía real del pago de una adquisición con arreglo al artículo 104 o 105 no primará sobre la prelación de una garantía real u otro derecho inscrito en un registro especial o anotado en un certificado de titularidad conforme a lo dispuesto en el artículo 49.

Artículo 107. Prelación entre garantías reales del pago de una adquisición concurrentes

La prelación entre garantías reales del pago de una adquisición concurrentes se determinará con arreglo a las reglas generales de prelación aplicables a las garantías reales no destinadas al pago de una adquisición, a menos que una de las garantías reales del pago de una adquisición lo sea de un proveedor y se haya hecho oponible a terceros dentro del plazo previsto en el artículo 105, en cuyo caso la garantía real del pago de una adquisición de ese proveedor gozará de prelación respecto de todas las garantías reales del pago de una adquisición concurrentes.

Artículo 108. Prelación de una garantía real del pago de una adquisición frente al derecho de un acreedor judicial

Una garantía real del pago de una adquisición que se haga oponible a terceros dentro del plazo previsto en el artículo 105 gozará de prelación frente a los derechos de un acreedor no garantizado, que de lo contrario gozaría de prelación con arreglo al artículo 52.

Artículo 109. Prelación de una garantía real del pago de una adquisición sobre un bien fijo o incorporado a un inmueble frente a todo gravamen anteriormente inscrito sobre dicho inmueble

Una garantía real del pago de un bien corporal que vaya a convertirse en un bien fijo o incorporado a un inmueble gozará de prelación frente a terceros con derechos existentes sobre dicho inmueble, que no sean un gravamen por el que se garantice un préstamo obtenido para la construcción del inmueble, a condición de que se haya inscrito en el registro de la propiedad inmobiliaria una notificación de la garantía real del pago de una adquisición en un plazo de [un breve plazo, por ejemplo, 30 días, que fijará el Estado promulgante] días a partir del momento en que el bien corporal pasó a ser un bien fijo de dicho inmueble.

Artículo 110. Prelación de una garantía real del pago de una adquisición sobre el producto de un bien corporal

Variante A*

1. Una garantía real del pago del producto de un bien corporal que no sean existencias ni bienes de consumo gozará de la misma prelación que una garantía real del pago de una adquisición sobre ese bien.
2. Una garantía real sobre el producto de existencias gozará de la misma prelación que una garantía real del pago de esas existencias, salvo si el producto consiste en créditos por cobrar, títulos negociables, derechos al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria o derechos a percibir el producto de una promesa independiente.
3. La prelación prevista en el párrafo 1 o 2 del presente artículo estará supeditada a que el acreedor garantizado que financie la adquisición notifique a los acreedores garantizados que, antes de que ese producto nazca, hayan inscrito una notificación respecto de una garantía real sobre bienes de la misma índole que el producto.

Variante B

Si una garantía real del pago de una adquisición constituida sobre un bien corporal es oponible a terceros, la garantía real sobre el producto gozará de la misma prelación que una garantía real no destinada a respaldar el pago de una adquisición.

Artículo 111. Las garantías reales del pago de una adquisición como garantías reales en el procedimiento de insolvencia

En el caso de un procedimiento de insolvencia relacionado con el deudor, las disposiciones aplicables a las garantías reales se aplicarán también a las garantías reales del pago de adquisiciones.

Variante B: Enfoque no unitario**

Artículo 112. Métodos de financiación de las adquisiciones

1. Las disposiciones sobre las garantías reales del pago de una adquisición en el contexto del enfoque no unitario son idénticas a las adoptadas en el contexto del enfoque unitario.
2. Todos los acreedores, tanto los proveedores como los prestamistas, podrán adquirir una garantía real del pago de una adquisición de conformidad con las disposiciones que rigen las garantías reales del pago de una adquisición.

* Un Estado podrá adoptar la variante A del artículo 110 si adopta la variante A del artículo 105, o la variante B del artículo 110 si adopta la variante B del artículo 105.

** Un Estado podrá adoptar la variante A (enfoque unitario), es decir, los artículos 103 a 111, o la variante B (enfoque no unitario), es decir, los artículos 112 a 126.

3. Podrá preverse un régimen de financiación de adquisiciones basado en los derechos de retención de la titularidad y los derechos de arrendamiento financiero de conformidad con el artículo 188.
4. Un prestamista podrá adquirir el beneficio de un derecho de retención de la titularidad y de un derecho de arrendamiento financiero mediante una cesión o una subrogación.

Artículo 113. Equivalencia entre un derecho de retención de la titularidad y un derecho de arrendamiento financiero y una garantía real del pago de una adquisición

Las reglas aplicables a la financiación de adquisiciones reportarán resultados económicos funcionalmente equivalentes entre sí, con independencia de que el derecho del acreedor sea un derecho de retención de la titularidad, un derecho de arrendamiento financiero o una garantía real del pago de una adquisición.

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si se deberían conservar, revisar según proceda o suprimir los artículos 112 y 113 abordando en el comentario las cuestiones a que se refieren.]

Artículo 114. Eficacia jurídica de un derecho de retención de la titularidad y de un derecho de arrendamiento financiero

1. Un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero sobre un bien corporal tendrá eficacia jurídica únicamente si el acuerdo de venta o de arrendamiento se ha concertado o se prueba por un escrito que, unido a la conducta entre las partes, indique la intención del vendedor o del arrendador de retener la propiedad.
2. El escrito deberá existir a más tardar en el momento en que el comprador o el arrendador obtenga la posesión del bien corporal.

Artículo 115. Derecho del comprador o del arrendatario a constituir una garantía real

1. Un comprador o un arrendatario podrán constituir una garantía real sobre un bien corporal objeto de un derecho de retención de la titularidad o de un derecho de arrendamiento financiero.
2. El importe máximo que cabrá obtener mediante la garantía real corresponderá al valor del bien corporal que rebase la suma adeudada al vendedor o al arrendador financiero.

Artículo 116. Oponibilidad a terceros de un derecho de retención de la titularidad o de un derecho de arrendamiento financiero sobre bienes de consumo

Un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero sobre bienes de consumo serán oponibles a terceros una vez celebrado el contrato de venta o de arrendamiento, siempre y cuando este derecho se haga constar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.

Artículo 117. Oponibilidad a terceros de un derecho de retención de la titularidad sobre un bien corporal

Variante A*

1. Una garantía real para financiar adquisiciones, el derecho de retención de la titularidad o el derecho de arrendamiento financiero sobre un bien corporal que no constituya existencias ni bienes de consumo será oponible a terceros únicamente si:

- a) El comprador o el arrendador conserva la posesión del bien corporal; o
- b) Se inscribe una notificación al respecto en el registro general de garantías reales a más tardar [un plazo breve, por ejemplo de 30 días, que fijará el Estado promulgante] días después de que el comprador o el arrendatario obtenga la posesión del bien corporal.

2. El derecho de retención de la titularidad o el derecho de arrendamiento financiero sobre existencias serán oponibles a terceros únicamente si:

- a) El vendedor o el arrendador conserva la posesión de las existencias; o si
- b) Antes de la entrega de las existencias al comprador o al arrendatario:
 - i) Se inscribe una notificación al respecto en el registro general de las garantías reales; y
 - ii) Un acreedor garantizado que goce de una garantía real sin fines de adquisición inscrita anteriormente y constituida por el comprador o el arrendatario sobre existencias del mismo tipo recibe una notificación del vendedor o del arrendador en el sentido de que ese vendedor o arrendador se propone invocar el derecho de retención de la titularidad o el derecho de arrendamiento financiero.

c) En la notificación que se menciona en el apartado 2 b) ii) del presente artículo se deberían describir las existencias con precisión suficiente para que el acreedor garantizado pueda determinar la naturaleza de las existencias sujetas al derecho de retención de la titularidad o al derecho de arrendamiento financiero.

3. Una única notificación, efectuada con arreglo al apartado 2 b) ii) del presente artículo, podrá abarcar los derechos de retención de la titularidad y los derechos de arrendamiento financiero en el marco de operaciones múltiples entre las mismas partes, sin necesidad de que se especifique cada operación en la notificación. La notificación será válida únicamente para los derechos sobre bienes corporales cuya posesión obtenga el comprador o el arrendatario en un plazo de [indíquese un plazo, por ejemplo de cinco años] años a partir de la fecha de la notificación.

Variante B

Una garantía real del pago de una adquisición, el derecho de retención de la titularidad o el derecho de arrendamiento financiero sobre los bienes corporales que no sean bienes de consumo serán oponibles a terceros únicamente si:

- a) El vendedor o el arrendador conservan la posesión del bien corporal; o

* Un Estado podrá adoptar la variante A o la variante B del artículo 117.

b) Se inscribe una notificación al respecto en el registro general de las garantías reales a más tardar [un plazo breve, por ejemplo de 30 días, que fijará el Estado promulgante] días después de que el comprador o el arrendatario obtengan la posesión del bien corporal.

Artículo 118. Suficiencia de una sola notificación

1. Bastará con inscribir una sola notificación en el registro general de las garantías reales para obtener la oponibilidad a terceros de un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero en el marco de todas las operaciones concertadas entre las mismas partes antes o después de la inscripción, en la medida en que recaigan sobre bienes corporales que correspondan a la descripción dada en la notificación.
2. Las disposiciones de la presente Ley sobre el sistema de registro se aplicarán [con las modificaciones terminológicas pertinentes] a la inscripción de un derecho de retención de la titularidad y de un derecho de arrendamiento financiero.

Artículo 119. Consecuencias de que no se obtenga la oponibilidad a terceros de un derecho de retención de la titularidad o de un derecho de arrendamiento financiero

Si un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero no es oponible a terceros, la propiedad del bien frente a terceros pasará al comprador o al arrendatario, y el vendedor o el arrendador dispondrán de una garantía real sobre el bien, a reserva de las disposiciones de la presente Ley aplicables a las garantías reales.

Artículo 120. Oponibilidad a terceros del derecho de retención de la titularidad o del derecho de arrendamiento financiero sobre un bien incorporado a un bien inmueble

1. El derecho de retención de la titularidad o el derecho de arrendamiento financiero sobre un bien corporal que se convierta en un bien fijo de un bien inmueble será oponible a terceros con derechos sobre ese bien inmueble que estén inscritos en el registro de propiedad inmobiliaria solamente si se ha inscrito en el registro de propiedad inmobiliaria a más tardar [un breve plazo, por ejemplo de 30 días, que fijará el Estado promulgante] días después de que el bien corporal haya pasado a ser un bien fijo del inmueble.
2. Si un vendedor o un arrendador no inscribe, en el plazo previsto en el párrafo 1 del presente artículo, una notificación de su derecho de retención de la titularidad o de su derecho de arrendamiento financiero sobre un bien corporal que haya pasado a ser un bien incorporado a un inmueble, se considerará que el derecho de retención de la titularidad del vendedor o el derecho de arrendamiento financiero del arrendador constituye una garantía real.

Artículo 121. Existencia de una garantía real sobre el producto de bienes corporales objeto de un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero

Un vendedor o un arrendador que gocen de un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero sobre un bien corporal tendrán una garantía real sobre el producto de dicho bien corporal.

Artículo 122. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre el producto de un bien corporal objeto de un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero

1. Toda garantía real sobre el producto a que se hace referencia en el artículo 121 será oponible a terceros únicamente si el producto ha sido descrito en términos genéricos en la notificación inscrita por la que se hizo oponible a terceros el derecho de retención de la titularidad o el derecho de arrendamiento financiero o si el producto consiste en dinero, créditos por cobrar, títulos negociables o derechos al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria.
2. Si el producto no ha sido descrito en términos genéricos en la notificación inscrita o no consiste en los tipos de bienes enumerados en el párrafo 1 del presente artículo, la garantía real sobre el producto será oponible a terceros durante [un breve plazo, por ejemplo, de 30 días, que fijará el Estado promulgante] días después de que nazca el producto y con carácter continuo posteriormente, si se le hizo oponible a terceros por uno de los métodos enumerados en el artículo 18 o 20 antes del vencimiento de ese plazo.

Artículo 123. Prelación de una garantía real sobre el producto de un bien corporal

Variante A*

1. Si un derecho de retención de titularidad o un derecho de arrendamiento financiero es oponible a terceros, la garantía real sobre el producto al que se alude en el artículo 121 gozará de prioridad frente a toda garantía real sobre el mismo bien.
2. Si un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero es oponible a terceros, la garantía real sobre el producto de las existencias adquiridas al que se hace referencia en el artículo 121 gozará de la misma prelación que un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero sobre dichas existencias, salvo cuando el producto consista en créditos por cobrar, títulos negociables, derechos al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria y derechos a recibir el producto de una promesa independiente.
3. La prelación a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo estará supeditada a que el vendedor o arrendador notifique a ese respecto a todo acreedor garantizado que, antes de que dicho producto nazca, haya inscrito una

* Un Estado podrá adoptar la variante A del artículo 123 si adopta la variante A del artículo 117, o la variante B del artículo 123 si adopta la variante B del artículo 117.

notificación relativa a una garantía real sobre bienes de la misma índole que el producto de las existencias.

Variante B

1. Si un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero sobre un bien corporal es oponible a terceros, la garantía real sobre el producto a que se hace referencia en el artículo 121 gozará de la misma prioridad que una garantía real no destinada a la adquisición si la garantía real sobre el producto es oponible a terceros conforme a lo dispuesto en el artículo 122.
2. La regla que se establece en el párrafo 1 del presente artículo se aplicará también al producto de un bien corporal sujeto a una garantía real del pago de una adquisición.

[Artículo 124. Ejecución de un derecho de retención de la titularidad o de un derecho de arrendamiento financiero]

1. Las reglas relativas a la ejecución de un derecho de retención de la titularidad o un derecho de arrendamiento financiero sobre un bien corporal a raíz de un incumplimiento deberían ocuparse de:
 - a) La forma en que el vendedor o el arrendador podrán obtener la posesión del bien corporal;
 - b) Si el vendedor o el arrendador están obligados o no a enajenar el bien corporal y, en caso afirmativo, la forma de hacerlo;
 - c) La cuestión de si el vendedor o el arrendador pueden retener un superávit; y
 - d) La cuestión de si el vendedor o el arrendador tienen alguna reclamación frente al comprador o el arrendatario por eventuales deficiencias.
2. La ley que se aplique a la ejecución de una garantía real a raíz de un incumplimiento será aplicable a la ejecución de un derecho de retención de la titularidad o de un derecho de arrendamiento financiero tras un incumplimiento, sin que con ello se menoscabe la coherencia de la ley aplicable a la venta y al arrendamiento.]

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee observar que el artículo 124 se basa en la recomendación 200 de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas, así como examinar su fondo, porque en su formulación actual no se ajusta al de una ley modelo.]

Artículo 125. Ley aplicable a un derecho de retención de la titularidad o a un derecho de arrendamiento financiero

Las disposiciones sobre conflicto de leyes de la presente Ley que se apliquen a las garantías reales se aplicarán también a los derechos de retención de la titularidad y a los derechos de arrendamiento financiero.

Artículo 126. Derecho de retención de la titularidad o derecho de arrendamiento financiero en un procedimiento de insolvencia

En el caso de un procedimiento de insolvencia respecto del deudor,

Variante A*

las disposiciones de la presente Ley que se apliquen a las garantías reales se aplicarán también a los derechos de retención de la titularidad y los derechos de arrendamiento financiero.

Variante B

las disposiciones de la presente Ley que se apliquen a los derechos de propiedad de terceros se aplicarán también a los derechos de retención de la titularidad y a los derechos de arrendamiento financiero.

Capítulo X. Conflicto de leyes

[Nota para el Grupo de Trabajo: El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si conviene o no conservar el capítulo X en el proyecto de ley modelo. Si decidiera eliminarlo, cabría explicar en el comentario que los Estados que desearan incluir disposiciones sobre conflicto de leyes en su ley de las operaciones garantizadas (o en otra ley) podrían aplicar las recomendaciones de la Guía sobre las Operaciones Garantizadas.]

Artículo 127. Ley aplicable a las garantías reales sobre bienes corporales

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 2 a 4 y en los artículos 128 y 131, la ley aplicable a la constitución de toda garantía real sobre bienes corporales, su oponibilidad a terceros y su grado de prelación será la ley del Estado en que esté situado el bien.
2. La ley aplicable a las cuestiones mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo respecto de una garantía real sobre un bien corporal de un determinado tipo que suela utilizarse en más de un Estado será la ley del Estado en que esté situado el otorgante.
3. Si una garantía real sobre un bien corporal es objeto de inscripción en un registro especial o de anotación en un certificado de titularidad que prevean la inscripción o anotación de una garantía real, la ley aplicable a las cuestiones mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo será la ley del Estado bajo cuya jurisdicción se mantenga el registro o se expida el certificado de titularidad.
4. La ley aplicable al grado de prelación de una garantía real sobre un bien corporal que se haya hecho oponible a terceros mediante la posesión de un documento negociable frente a otra garantía real concurrente que se haya hecho oponible a terceros mediante otro método será la ley del Estado en que esté situado el documento.

* Los Estados podrán adoptar la variante A o la variante B del artículo 126.

Artículo 128. Ley aplicable a las garantías reales sobre bienes corporales en tránsito o destinados a la exportación

Toda garantía real sobre bienes corporales que estén en tránsito, o que se vayan a exportar del Estado en que se encuentren en el momento de constituirse la garantía real, podrá constituirse y hacerse valer frente a terceros con arreglo a las leyes del Estado en que estuviesen situados los bienes en el momento de la constitución, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 127, o con arreglo a las leyes del Estado de destino final, siempre que los bienes lleguen a ese Estado en un plazo de [un plazo breve, por ejemplo, de 30 días, que fijará el Estado promulgante] días a contar desde el momento en que se haya constituido la garantía real, con arreglo a las leyes del Estado de destino final.

Artículo 129. Ley aplicable a las garantías reales sobre bienes inmateriales

La ley aplicable a la constitución de toda garantía real sobre un bien inmaterial, a su oponibilidad a terceros y a su grado de prelación será la ley del Estado en que esté situado el otorgante.

Artículo 130. Ley aplicable a una garantía real sobre créditos por cobrar nacidos de una venta, de un arrendamiento o de una operación respaldada por un acuerdo de garantía relativo a un bien inmueble

1. La ley aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros y el grado de prelación de toda garantía real sobre un crédito por cobrar nacido de una venta, de un arrendamiento o de una operación respaldada por un acuerdo de garantía relativo a un bien inmueble será la ley del Estado en que esté situado el cedente.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, la ley aplicable a los conflictos de prelación relativos a los derechos de un demandante concurrente inscrito en el registro de la propiedad inmobiliaria será la ley del Estado bajo cuya jurisdicción se mantenga dicho registro.
3. La regla enunciada en el párrafo anterior se aplicará únicamente si la inscripción es pertinente en virtud de dicha ley a la prelación de una garantía real sobre el crédito por cobrar.

Artículo 131. Ley aplicable a la oponibilidad a terceros de garantías reales sobre determinados tipos de bienes mediante inscripción registral

Si el Estado en que está situado el otorgante reconoce la inscripción registral como método para que una garantía real sobre un título negociable o un derecho al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria surta efecto frente a terceros, será la ley de ese Estado la que determine si esa garantía ha pasado a ser oponible a terceros mediante la inscripción registral efectuada conforme a sus leyes.

**Artículo 132. Ley aplicable a las garantías reales
sobre el producto de un bien**

1. La constitución de toda garantía real sobre el producto de un bien se regirá por la ley aplicable a la constitución de la garantía real sobre el bien originalmente gravado del cual se obtenga el producto.
2. La ley aplicable a la oponibilidad a terceros y la prelación de toda garantía real sobre el producto de un bien será la ley que rija la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real constituida sobre bienes del mismo tipo que el producto.

**Artículo 133. Ley aplicable a los derechos y obligaciones
del otorgante y del acreedor garantizado**

La ley aplicable a los derechos y obligaciones recíprocos del otorgante y el acreedor garantizado emanados de su acuerdo de garantía será la ley que hayan elegido y, si no hubieran elegido la ley aplicable, la ley por la que se rija el acuerdo de garantía.

**Artículo 134. Ley aplicable a los derechos y obligaciones
de los terceros deudores y los acreedores garantizados**

La ley aplicable a los créditos por cobrar será también la ley que rija:

- a) La relación entre el deudor y el cesionario del crédito por cobrar;
- b) Las condiciones en que la cesión de un crédito por cobrar podrá invocarse frente al deudor de ese crédito, incluso la posibilidad de que el deudor, la parte obligada o el emisor hiciera valer o no un acuerdo de intransmisibilidad; y
- c) La determinación de que las obligaciones del deudor del crédito se hayan cumplido o no.

Artículo 135. Ley aplicable a la ejecución de una garantía real

A reserva de lo dispuesto en el artículo 140, la ley aplicable a las cuestiones relativas a la ejecución de la garantía real:

- a) Constituida sobre un bien corporal será la ley del Estado en que tenga lugar la ejecución; y
- b) Constituida sobre un bien inmaterial será la ley que rija la prelación de la garantía.

Artículo 136. Significado de la “ubicación” del otorgante

1. A efectos de las disposiciones de la presente Ley relativas al conflicto de leyes, el otorgante estará situado en el Estado en que se encuentre su establecimiento.
2. Si el otorgante está establecido en más de un Estado, su establecimiento será aquel en que se ejerza la administración central.
3. Si no tiene un establecimiento, se hará referencia a su residencia habitual.

Artículo 137. Momento aplicable al determinar la ubicación

1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, cuando en las disposiciones relativas al conflicto de leyes se mencione la ubicación de los bienes o del otorgante, se entenderá que se hace referencia, a efectos de las cuestiones relacionadas con la constitución de la garantía real, al lugar en que se encontraban los bienes o el otorgante en el momento de constituirse la garantía real y, a efectos de las cuestiones relativas a la oponibilidad a terceros y la prelación, al lugar en que se encontraban los bienes o el otorgante en el momento de plantearse la cuestión;
2. Si los derechos de las partes reclamantes concurrentes sobre un bien gravado se constituyeron y pasaron a ser oponibles a terceros antes del cambio de ubicación del bien o del otorgante, cuando en las disposiciones relativas al conflicto de leyes se mencione la ubicación de los bienes o del otorgante se entenderá, en lo que respecta a la oponibilidad a terceros y a las cuestiones de prelación, que se refieren al lugar anterior al cambio de ubicación.

Artículo 138. Exclusión de la remisión

En las disposiciones relativas al conflicto de leyes deberá entenderse que toda remisión a “la ley” de otro Estado como ley que rige una determinada cuestión se refiere a la ley vigente en ese Estado para cuestiones que no sean las reglas sobre conflicto de leyes.

Artículo 139. Orden público y reglas imperativas de alcance internacional

1. El tribunal del foro solo puede negarse a aplicar la ley determinada en las disposiciones relativas al conflicto de leyes cuando los efectos de su aplicación sean manifiestamente contrarios al orden público del foro.
2. Las disposiciones sobre conflicto de leyes no impiden que el tribunal del foro aplique las disposiciones de su propia ley que, independientemente de las reglas de conflicto de leyes, deban aplicarse incluso a situaciones internacionales.
3. Las reglas enunciadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo no permiten la aplicación de disposiciones de la ley del foro a la oponibilidad a terceros o a la prelación de una garantía real.

Artículo 140. Efecto de la apertura de un procedimiento de insolvencia en la ley aplicable a las garantías reales

1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, la apertura de un procedimiento de insolvencia no sustituye las normas sobre conflicto de leyes que determinan la ley aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución de una garantía real [y, si el Estado promulgante adopta el enfoque no unitario, al derecho de retención de titularidad y el derecho de arrendamiento financiero].
2. La disposición del párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a los efectos que tenga en esas cuestiones la aplicación del régimen de insolvencia del Estado en que se abra el procedimiento de insolvencia a cuestiones como la anulación, el trato de los acreedores garantizados, la clasificación de demandas o la distribución del producto.

Artículo 141. Reglas especiales para situaciones en que el derecho aplicable sea el de un Estado con varias unidades territoriales

1. En aquellas situaciones en que la ley aplicable a una cuestión sea la de un Estado integrado por varias unidades territoriales, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, toda referencia a la ley de un Estado compuesto por varias unidades territoriales se entenderá referida a la ley de la unidad territorial pertinente, determinada en función de la ubicación del otorgante o de un bien gravado o de otra manera con arreglo a las normas sobre conflicto de leyes de la presente Ley, y, en la medida en que sea aplicable a dicha unidad territorial, se entenderá referida a la ley del Estado integrado por varias unidades territoriales propiamente dicho.
2. Si, en virtud de sus disposiciones relativas al conflicto de leyes, la ley aplicable es la de un Estado compuesto por varias unidades territoriales o la de una de sus unidades territoriales, serán las reglas internas sobre conflicto de leyes vigentes en dicho Estado multiterritorial o en su unidad territorial las que determinen si se aplican las reglas sustantivas de derecho del Estado multiterritorial o las de una determinada unidad territorial de dicho Estado.

Capítulo XI. Disposiciones transitorias

Artículo 142. Fecha de entrada en vigor

1. La presente Ley entrará en vigor el [fecha que indicará el Estado promulgante] [seis meses después de [fecha que indicará el Estado promulgante]].
2. A partir de su entrada en vigor, la presente Ley se aplicará a todas las operaciones comprendidas en su ámbito, concertadas antes o después de dicha fecha, a reserva de lo dispuesto en los artículos 143 a 146.

Artículo 143. Inaplicabilidad de la ley a las actuaciones abiertas antes de su entrada en vigor

1. La presente Ley no se aplicará a las cuestiones que se estén dirimiendo en el marco de un litigio o de otro procedimiento vinculante de solución de controversias antes de la fecha de entrada en vigor.
2. Si la ejecución de una garantía real ha comenzado antes de la fecha de entrada en vigor, podrá continuar en virtud del régimen vigente con anterioridad a ella.

Artículo 144. Constitución de una garantía real

La normativa legal anterior determinará si se constituyó una garantía real antes de la fecha de entrada en vigor.

Artículo 145. Oponibilidad a terceros de una garantía real

1. Una garantía real que haya pasado a ser oponible a terceros conforme a la normativa legal anterior conservará su eficacia frente a terceros hasta:
 - a) El momento en que deje de ser oponible en virtud de la normativa legal anterior; o, de ocurrir antes, hasta;

b) La expiración de un período de transición de [plazo, por ejemplo de seis meses, que indicará el Estado promulgante] meses después de la fecha de entrada en vigor.

2. Si se cumplen las prescripciones relativas a la oponibilidad a terceros antes de que esta haya cesado en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, se mantendrá la oponibilidad a terceros.

Artículo 146. Prelación de una garantía real

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente artículo, la prelación de una garantía real se regirá por la presente Ley.

2. El momento en que la garantía real a que se hace referencia en el artículo 145 pasó a ser oponible a terceros o fue objeto de una inscripción de notificación en virtud de la normativa legal anterior será el momento que servirá para determinar la prelación de dicha garantía.

3. La prelación de una garantía real será determinada por la normativa legal vigente antes de la entrada en vigor cuando:

a) La garantía real y los derechos de todos los reclamantes concurrentes hubieran nacido antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley; y

b) No se haya producido ningún cambio en la situación jurídica de la prelación de esos derechos desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

4. La situación jurídica de la prelación de una garantía real ha cambiado si:

a) La garantía real era oponible a terceros en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 145, y posteriormente dejó de ser oponible a terceros; o

b) La garantía real no era oponible a terceros en la fecha de entrada en vigor de la presente ley y posteriormente pasó a serlo.

VI. CONTRATACIÓN PÚBLICA

A. Nota de la Secretaría sobre directrices para la promulgación de un reglamento de la contratación pública de conformidad con el artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública

(A/CN.9/770)

[Original: inglés]

1. En el artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDMI de 2011 sobre la Contratación Pública¹ se ha previsto la promulgación de reglamentos pertinentes que sirvan para cumplir los objetivos y aplicar las disposiciones de la Ley Modelo. Varias disposiciones de la Ley Modelo indican expresamente que deben complementarse con un reglamento de la contratación pública. En la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública, aprobada por la Comisión en su 45º período de sesiones, en 2012², se observa, además, que el Estado promulgante puede decidir complementar otras disposiciones de la Ley Modelo con reglamentaciones sobre contratación pública, aun cuando en ellas no se haga remisión expresa a un reglamento. A lo largo de toda la Guía figuran sugerencias acerca del contenido del reglamento.

2. Para facilitar la consulta, se consideró conveniente unificar las disposiciones de la Ley Modelo y de la Guía y señalar los temas principales del reglamento de la contratación pública en un solo documento que se ofrecerá en el sitio web de la CNUDMI como suplemento de la Guía. En la presente nota se somete a consideración de la Comisión una propuesta relativa a ese documento.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), anexo I.*

² *Ibid., sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 46.*

Directrices para la promulgación de un reglamento de la contratación pública de conformidad con el artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública

I. Introducción

1. En la Ley Modelo de la CNUDMI de 2011 sobre la Contratación Pública¹ (artículo 4 [\[**hiperenlace**\]](#)) se ha previsto que los Estados promulguen reglamentos de la contratación pública destinados a facilitar la aplicación de la Ley Modelo y el logro de sus objetivos. El propósito del reglamento es complementar el marco legislativo del régimen de la contratación pública, tanto para pormenorizar los procedimientos autorizados por la Ley Modelo como para tener en cuenta las circunstancias peculiares y tal vez variables del Estado promulgante.
2. Varias disposiciones de la Ley Modelo indican expresamente que deben complementarse con un reglamento de la contratación pública. Además, el Estado promulgante puede decidir complementar otras disposiciones de la Ley Modelo aun cuando estas no se remitan expresamente al reglamento correspondiente. En ambos casos esa normativa no debería contradecir la Ley Modelo ni mermar la eficacia de sus disposiciones.
3. Entre los principales ejemplos de trámites que convendría perfilar más en el reglamento de la contratación pública cabe citar los siguientes: el modo de publicación de diversos tipos de información (artículos 5, 6, 18.2, 23, 33.1 y 34.5 [\[**hiperenlaces**\]](#)); las medidas para garantizar la autenticidad, la integridad y la confidencialidad de la información comunicada durante el proceso de contratación (artículo 7.5 [\[**hiperenlace**\]](#)); los motivos para limitar la participación en la contratación (artículo 8 [\[**hiperenlace**\]](#)); el cálculo de los márgenes de preferencia y aplicación de criterios socioeconómicos en la evaluación de las ofertas (artículo 11 [\[**hiperenlace**\]](#)); la estimación del valor de la contratación (artículo 12 [\[**hiperenlace**\]](#)); los requisitos relativos a la duración de la moratoria (artículo 22.2 c) [\[**hiperenlace**\]](#)); los requisitos relativos al expediente del procedimiento de adjudicación (artículo 25.1 w) y 5 [\[**hiperenlace**\]](#)); la duración máxima de los acuerdos marco cerrados (artículo 59.1 a) [\[**hiperenlace**\]](#)); el código de conducta (artículo 26 [\[**hiperenlace**\]](#)), y la limitación de la cuantía del contrato adjudicado en casos de urgencia por el método de la negociación competitiva o el de la contratación con un solo proveedor (donde se limita la cantidad al nivel necesario para hacer frente a las circunstancias urgentes) (véase el comentario de la Guía sobre las disposiciones pertinentes de los párrafos 4 y 5 del artículo 30 [\[**hiperenlace**\]](#)).
4. Además de que la utilización del reglamento constituye una práctica óptima, la falta de una reglamentación de la contratación pública en algún punto en que la Ley Modelo remita a esa reglamentación podría privar a la entidad adjudicadora de las facultades necesarias para adoptar las medidas en cuestión. Entre esos casos cabe citar: la limitación de la participación en los procesos de contratación pública (artículo 8 [\[**hiperenlace**\]](#)); el permiso y demás trámites necesarios para otorgar

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), anexo I.*

un margen de preferencia a los proveedores o contratistas nacionales (artículo 11 [**hiperlance**]), y la utilización del método de la solicitud de cotizaciones, ya que ese método de contratación solamente puede utilizarse cuando se trata de contratos de valor inferior al umbral establecido en el reglamento de la contratación pública (artículo 29.2 [**hiperlance**]).

5. Como se indica en la Guía para la incorporación de la Ley Modelo al derecho interno, aprobada por la Comisión en su 45º período de sesiones, en 2012², toda remisión al “reglamento de la contratación pública” deberá interpretarse de conformidad con las tradiciones jurídicas del Estado promulgante; ese concepto puede abarcar cualquier instrumento que utilice el Estado promulgante para aplicar sus leyes. Esas tradiciones jurídicas también pueden servir para determinar las cuestiones que es habitual abordar mediante directrices³. En el presente documento no se examinan esos aspectos. En él se reúnen todas las disposiciones de la Ley Modelo y de la Guía en que se destacan los principales temas que han de examinarse en relación con el reglamento de la contratación pública a efectos de cumplir los objetivos y aplicar las disposiciones de la Ley Modelo.

6. Las disposiciones pertinentes están agrupadas por temas. En primer lugar se examinan asuntos generales relacionados con varios artículos de la Ley Modelo (entre ellos las políticas socioeconómicas y la información reservada). Posteriormente se abordan aspectos vinculados a determinados artículos del Capítulo I de la Ley Modelo, expuestos en el orden de los artículos pertinentes. Las cuestiones relativas a los diversos métodos y técnicas de contratación se examinan en relación con cada método y técnica. Por último, se destacan aspectos relacionados con la reglamentación de la contratación u otras reglamentaciones aplicables en el contexto de los procedimientos de recurso.

7. Habida cuenta de que el documento únicamente abarca las principales cuestiones, su objetivo no es examinar exhaustivamente los aspectos que han de abordarse en el reglamento de la contratación pública. En particular, y en consonancia con el alcance de la Ley Modelo y la Guía para su incorporación al derecho interno, el documento no trata de cuestiones relativas a la planificación de la contratación y la gestión de los contratos que no se relacionen directamente con las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo. Puede justificarse regular detalladamente esas etapas del ciclo de la contratación en los reglamentos correspondientes de los Estados promulgantes.

8. Por otra parte, como se indica en la Guía⁴, la Ley Modelo y el reglamento de la contratación pública que se promulgue de conformidad con su artículo 4 no bastarán para garantizar el funcionamiento efectivo del régimen de la contratación pública del Estado promulgante. Es preciso adoptar medidas en otros ámbitos del derecho, así como de índole institucional y administrativa. En la Guía se indican las medidas que han de adoptarse al margen del marco jurídico de la contratación

² *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 46. El texto de la Guía puede consultarse, en la fecha de publicación del presente documento, en http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2012Guide.html.

³ Párr. 2 del comentario sobre el artículo 4.

⁴ Párrs. 58 a 81 de la Primera Parte.

pública con objeto de garantizar la aplicación efectiva de la Ley Modelo⁵. Esas medidas no se examinan en el presente documento.

II. Temas generales

A. Las políticas socioeconómicas en la contratación pública

9. Las políticas socioeconómicas que pueden o deben aplicarse a lo largo del proceso de la contratación pública han de establecerse en el reglamento o en otras normas jurídicas del Estado promulgante (véanse el artículo 2 o) de la Ley Modelo [\[**hiperenlace**\]](#) y el comentario que figura en la Introducción del Capítulo I [\[**hiperenlace**\]](#), así como el comentario de la Guía sobre los artículos 2 o) y 8 a 11 [\[**hiperenlaces**\]](#)).

10. Si se establecen en el reglamento de la contratación pública, este deberá abordar, entre otras cosas y cuando corresponda, los siguientes aspectos:

a) Las situaciones en que la entidad adjudicadora pueda o deba limitar la participación de ciertas categorías de proveedores o contratistas en el proceso de contratación (por ejemplo, declarando que el ámbito de la contratación es exclusivamente nacional) (véanse el artículo 8 y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#));

b) Todo margen u otra clase de preferencia que pueda otorgarse a los proveedores o contratistas nacionales o a los bienes de origen interno al evaluar las ofertas y el método utilizado para calcularlo y aplicarlo (véanse el artículo 11 y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#));

c) Toda política socioeconómica que pueda o deba incorporarse en los criterios de calificación (por ejemplo, de carácter ambiental, ético o de otra índole), en la descripción del objeto del contrato adjudicable y en la definición de los criterios de evaluación (es decir, reconocer el cumplimiento de las políticas socioeconómicas sobrepasando el mínimo exigido) (véanse los artículos 9 a 11 y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#));

d) Una política socioeconómica en particular que justifique recurrir a un solo proveedor o contratista (véanse el artículo 30.5 e) y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#));

e) Las limitaciones que haya que imponer a las entidades adjudicadoras, en particular, prohibirles que adopten políticas arbitrariamente.

11. Si las políticas no se establecen en el reglamento de la contratación pública, este debería remitir directamente a los lectores a otras leyes y normas pertinentes, de manera que las entidades adjudicadoras estuvieran al corriente de los criterios socioeconómicos preceptivos que se aplicarían y del alcance de sus facultades discrecionales para aplicar otros criterios socioeconómicos, y de que los proveedores o contratistas pudieran estar seguros de que las políticas socioeconómicas se estuviesen aplicando de manera transparente y objetiva en el proceso de adjudicación del Estado promulgante.

⁵ *Ibid.*

12. En la Guía se advierte a los Estados promulgantes de las consecuencias adversas que puede tener incorporar políticas socioeconómicas en el proceso de contratación, así como incluir una lista amplia de criterios socioeconómicos o de circunstancias que den lugar a la aplicación de un margen de preferencia⁶.

B. Información reservada

13. Las facultades otorgadas a las entidades adjudicadoras para adoptar medidas especiales e imponer requisitos especiales a fin de proteger la información reservada, entre otras cosas, exonerar a las personas de revelar información, se aplican únicamente en la medida en que lo permita el reglamento de la contratación pública o cualquier otra norma jurídica del Estado promulgante (véanse el artículo 2.1 y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]).

14. Si el reglamento de la contratación pública aborda esas cuestiones, se deben determinar las clases de contratación en que la entidad adjudicadora podrá o deberá adoptar medidas e imponer requisitos para la protección de la información reservada. El reglamento de la contratación pública también debe regular, entre otras cosas:

a) Las medidas que pueden adoptarse. Entre las medidas que pueden invocarse figuran la protección de la confidencialidad de ciertas partes del expediente, la exoneración del anuncio público de la contratación y de la adjudicación del contrato y el recurso a la convocatoria directa (véanse los artículos 7.3 b), 24, 25.4 y 35.2 y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]), y

b) Los requisitos que pueden imponerse para proteger la información reservada sobre los proveedores, contratistas y subcontratistas, entre ellos, ciertos métodos e instrumentos para la transmisión de información (por ejemplo, sistemas de codificación) (véanse los artículos 7.3 b) y 24.4 y el comentario correspondiente [**hiperenlaces**]).

C. Contratos de poca cuantía

15. En el apartado b) del artículo 22.3 se exime de la aplicación preceptiva de una moratoria cuando el objeto de la contratación sea de poca cuantía [**hiperenlace**] y en el artículo 23.2 se exime a esas contrataciones del requisito del anuncio público de la adjudicación del contrato [**hiperenlace**]. (En el Capítulo II también se estipula un límite superior para el empleo de solicitudes de cotizaciones con arreglo al artículo 29.2 [**hiperenlace**]). En todos esos casos, la Ley Modelo se remite al reglamento de la contratación pública en lo que respecta a determinar el límite aplicable. Eso se debe a que no es posible establecer en la Ley Modelo un único umbral para los contratos de poca cuantía que sea apropiado para todos los Estados promulgantes y a que los umbrales apropiados para cada Estado pueden variar con la inflación y a medida que vayan cambiando también otras circunstancias económicas. Incumbe al órgano regulador que prepare el reglamento determinar la cuantía o las cuantías apropiadas de todos esos umbrales o límites.

⁶ Párrs. 9 a 27 de la Primera Parte, párrs. 26 a 33 de la introducción del Capítulo I y párrs. 7 a 13 del comentario sobre el artículo 11.

16. En otros casos en que se hace referencia a los contratos de poca cuantía, la Ley Modelo no exige que el reglamento establezca límites expresamente. Por ejemplo, las convocatorias a precalificación y licitación no tienen por qué publicarse a nivel internacional si la entidad adjudicadora determina que, en vista del poca cuantía del objeto del contrato adjudicable, únicamente los proveedores o contratistas nacionales tendrán interés en presentar ofertas (artículos 18.2 y 33.4 **[**hiperenlaces**]**). Por otra parte, una de las razones para justificar el empleo de una clase de licitación restringida y la convocatoria directa en los procedimientos de solicitud de propuestas es que el tiempo y los gastos necesarios para examinar y evaluar un gran número de ofertas resultarían desproporcionados con respecto al valor del objeto del contrato adjudicable (véanse los artículos 29.1 b) y 35.2 b) y el comentario correspondiente **[**hiperenlaces**]**).

17. El organismo u órgano regulador que prepare el reglamento de la contratación pública debería estudiar el enfoque adecuado para determinar lo que se consideraría contrato “de poca cuantía”, a saber, si podría o debería fijarse una cantidad máxima para que el contrato se considerara “de poca cuantía”. Por ejemplo, si el reglamento de la contratación pública debería fijar un umbral para todos los casos en que el régimen de la contratación pública se remitiera a un límite con respecto a los contratos de poca cuantía (incluido el límite superior para utilizar la solicitud de cotizaciones); si ese valor se aplicaría en todos los casos en que el régimen se remitiera a la “contratación de poca cuantía” (incluso cuando no se remitiera expresamente a un límite, como se ha explicado anteriormente), o si las circunstancias deberían indicar la conveniencia de aplicar diferentes límites y cantidades.

D. Comisiones cobradas por participar en el proceso de adjudicación

18. Como se indica en la Guía⁷, lo ideal sería que no se cobraran derechos por tener acceso a los sistemas de información de la entidad adjudicadora y utilizarlos. En consecuencia, en el reglamento de la contratación pública se debería recomendar que no se cobraran esos derechos o comisiones, por considerarse un factor disuasorio de la participación en el proceso de adjudicación que sería contrario a los principios y objetivos de la Ley Modelo. Si se decide cobrar comisiones por utilizar el sistema de comunicaciones, el reglamento debería exigir que ese procedimiento fuera transparente, justificado, razonable y proporcionado y que no fuera discriminatorio ni restringiera el acceso al proceso de adjudicación. Se puede exigir que se den a conocer el importe de la comisión aplicable y las razones para cobrarla y que se la considere una medida provisional (por ejemplo, hasta que se haya amortizado la inversión en el nuevo sistema de comunicaciones).

19. Una cuestión conexa es cobrar derechos por facilitar los documentos de precalificación o los pliegos de condiciones. Cuando esos documentos se cobren, el reglamento debe contener disposiciones que impidan que la entidad adjudicadora fije un precio excesivamente alto. Por ejemplo, puede exigirse que el precio que se cobre sea equivalente a los gastos reales en que haya incurrido la entidad adjudicadora para facilitar los documentos, es decir, para imprimirlos y enviarlos por correo. Debería indicarse lo que no debe intentarse recuperar poniendo un

⁷ Parr. 12 del comentario sobre el artículo 7.

precio a esos documentos, entre otras cosas, los gastos de preparación (por ejemplo, los honorarios de los consultores y los gastos de publicidad).

E. Cuestiones relativas a la subcontratación y las adquisiciones centralizadas

20. En el reglamento de la contratación pública deberían preverse medidas relacionadas con la formulación y utilización del régimen de adquisiciones que puedan dar lugar a discriminación o tener otras consecuencias perjudiciales. Los criterios utilizados para formular y utilizar el régimen de adquisiciones, por ejemplo, la participación de terceros en la elaboración del sistema de comunicaciones y el empleo de sistemas patentados, repercutirían directamente en la participación de los proveedores o contratistas en el proceso de contratación. También afectarían a las decisiones que se adoptaran con respecto a cobrar derechos por utilizar el sistema y a las decisiones de las entidades adjudicadoras sobre sus estrategias de contratación, en general, y en cada caso en particular.

21. Deben tenerse especialmente presentes las cuestiones relativas a la subcontratación de las adquisiciones, en particular los riesgos de que surjan conflictos de intereses entre las empresas si los terceros proveedores de servicios de tecnología de la información son remunerados sobre la base de comisiones por la utilización de servicios de mantenimiento y funcionamiento de plataformas electrónicas de adquisiciones como las subastas electrónicas inversas o los contratos marco abiertos, así como los riesgos relacionados con la influencia que puedan ejercer personas de afuera en las estrategias de contratación y los problemas vinculados a la acumulación y retención de aptitudes y conocimientos suficientes en la entidad adjudicadora, necesarios, entre otras cosas, para supervisar las actividades de esos terceros proveedores.

22. Cuando existan organismos encargados de las adquisiciones centralizadas que actúen como representantes de una o más entidades adjudicadoras y se promuevan las adquisiciones centralizadas a fin de aprovechar las economías de escala que pueden ofrecer, los reglamentos de la contratación pública deben garantizar que esos acuerdos puedan funcionar de manera transparente y eficaz. Se deben establecer medidas para evaluar los méritos relativos de esa clase de adquisiciones, normalizar los procedimientos y tener en cuenta las diferentes necesidades de cada contrato y de los distintos sectores del mercado de la contratación pública en general. Se deben tratar de solucionar los conflictos de intereses entre las empresas (las entidades encargadas de las adquisiciones centralizadas pueden tener interés en aumentar sus ganancias manteniendo altos los precios de sus tarifas y promoviendo adquisiciones que excedan de las necesidades de la entidad adjudicadora). Si el organismo encargado de las adquisiciones centralizadas emprende la planificación de futuras adquisiciones, el reglamento debe exigir que exista una interacción más estrecha entre el organismo y los probables usuarios finales antes de que comience el procedimiento, a efectos de que pueda adoptar una decisión acerca del grado apropiado de normalización y de la mejor manera de tener en cuenta las distintas necesidades (la calidad de la información que faciliten los usuarios finales será esencial. Es posible que las necesidades de los distintos ministerios u organismos no sean idénticas, razón por la cual algunos obtendrán una mayor rentabilidad

económica que otros si esas necesidades se normalizan sin hacer un análisis suficientemente profundo).

III. Temas que deberán tratarse en el reglamento de la contratación pública en el contexto de determinados artículos del Capítulo I de la Ley Modelo (Disposiciones generales) [\[hiperenlace**\]](#), expuestos en el orden de los artículos correspondientes**

Artículo 5. Publicación de textos jurídicos [\[hiperenlace**\]](#)**

1. El reglamento de la contratación pública debe determinar el modo y el medio de publicación de los textos jurídicos previstos en el párrafo 1 del artículo 5, o bien remitirse a las fuentes jurídicas relativas a la publicidad de las leyes, reglamentos y demás actos públicos. Si se determinan el modo y el medio de publicación, también se deberá:

a) Disponer un medio y un modo de publicación centralizada en un lugar común y de acceso fácil y amplio (la “gaceta oficial” u otra publicación equivalente);

b) Precisar que la información anunciada en el medio único centralizado debe ser auténtica y de fuente autorizada y tiene primacía con respecto a la información que pudiera difundirse por otros medios. También debe ser fácil de leer, comprender, interpretar y conservar;

c) Establecer normas en las que se defina la relación de ese medio único centralizado con otros posibles medios en los que podría aparecer la misma información y disponer normas que regulen la publicación en otros medios de difusión oficiales (por ejemplo, prohibir la publicación de la información en diferentes medios antes de publicarla en el medio centralizado, y exigir que la misma información publicada en diferentes medios contenga los mismos datos);

d) Regular la cuestión de los derechos o comisiones (como se indicó en la sección II.D del presente documento, lo ideal sería que no se cobrara comisión alguna por facilitar las leyes, reglamentos y demás textos jurídicos de aplicación general en relación con las adjudicaciones reguladas por el régimen de la contratación pública y toda modificación introducida en ellos).

2. También debe explicarse el significado de los requisitos de “acceso rápido” y “actualización sistemática” de los documentos. En la práctica, el requisito de que la información sea “accesible” significa que esta debe poderse obtener y leer sin tener que solicitar acceso. Eso implica la adopción de medidas especiales por parte de las autoridades públicas competentes (entre ellas, la publicación en medios de difusión oficiales) con objeto de asegurarse de que la información pertinente llegue a ser de dominio público. El requisito de “actualización sistemática” significa que la autoridad pública competente debe cerciorarse de que la información esté realmente actualizada y, por ende, sea fidedigna: la manera de cumplir esa obligación debería estar documentada para poder verificar que realmente se cumpla.

3. Si los Estados promulgantes desean promover la publicación de otros textos pertinentes y de utilidad práctica e importancia para los proveedores y contratistas (por ejemplo, directrices o manuales sobre contratación pública y otros documentos en que se proporcione información sobre aspectos importantes de las prácticas y los procedimientos nacionales correspondientes que puedan afectar a los derechos y obligaciones generales de los proveedores y contratistas), se debería precisar cuáles serían esos otros textos y las condiciones en que se publicarían.
4. En ausencia de otras normas jurídicas al respecto en el Estado promulgante, el reglamento de la contratación pública debe determinar los órganos del Estado que se encargarán de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en este artículo.

Artículo 6. Información sobre contratos próximamente adjudicables

[hiperenlace**]**

1. El reglamento de la contratación pública debería establecer la información que cabría publicar con arreglo al artículo. Al respecto, en la Guía se observa que facilitar información abundante, pero no pertinente, o que induzca a error, en vez de información cuidadosamente preparada, útil y pertinente, puede comprometer el propósito de comunicar esa clase de información⁸. Habrá que incluir, por ejemplo, los siguientes datos: el período que ha de abarcar la información relativa al contrato previsto, que podría ser de medio año, de un año o de otra duración; un preaviso sobre los contratos que se tenga previsto adjudicar próximamente, y la diferencia entre esa clase de notificaciones y otras clases de preavisos sobre futuros contratos, como una solicitud de manifestaciones de interés, que por lo general se publica conjuntamente con los procedimientos de solicitud de propuestas, o un preaviso de la contratación, que se exige en la mayoría de los casos de convocatoria directa con arreglo a los artículos 34 y 35 de la Ley Modelo **[**hiperenlaces**]**.
2. También deberían establecerse otras condiciones para la publicación de información, entre ellas las relativas al lugar y el medio de publicación, teniendo en cuenta las cuestiones señaladas anteriormente en relación con el artículo 5 **[**hiperenlace**]**.
3. En consonancia con lo que se indica en la Guía al respecto⁹, se debería evitar imponer el requisito de publicar esa clase de información. En cambio, debería establecerse la regla supletoria de publicar esa información a menos que existieran otras consideraciones que aconsejaran lo contrario: debe quedar a criterio de la entidad adjudicadora decidir caso por caso si debe o no publicarse.
4. Se pueden ofrecer incentivos para la publicación de esa información, por ejemplo, dando la posibilidad de abreviar el plazo para la presentación de ofertas en los casos en que la contratación se haya dado a conocer por adelantado. También podrá hacerse referencia a los casos en que la publicación de esa información sea particularmente conveniente, como cuando se prevea adjudicar un contrato de construcción de una obra compleja, o cuando el valor del contrato sobrepase determinado límite.

⁸ Párr. 2 del comentario sobre el artículo 6.

⁹ Párr. 7 del comentario sobre el artículo 6.

Artículo 7. Comunicaciones consignadas durante la contratación [\[hiperenlace**\]](#)**

1. En el reglamento deben explicarse los conceptos de “habitualmente empleados” y “plena y simultáneamente” que figuran en el artículo en relación con los requisitos de que los medios de comunicación sean los habitualmente empleados por los proveedores o contratistas en cuestión (lo que, por ejemplo, permite disponer de una conectividad y una interoperabilidad eficientes y asequibles) y de que los medios de comunicación que se utilicen en las reuniones garanticen, además, que los proveedores o contratistas puedan participar plena y simultáneamente en ellas, es decir, que puedan seguir en tiempo real todas las actuaciones de la reunión e intervenir frente a otros participantes, si es necesario (véase el artículo 7.4 [\[**hiperenlace**\]](#)). Se deben indicar las características de los medios de comunicación que puede utilizar la entidad adjudicadora en determinados tipos de contratación a fin de cumplir esos requisitos. Otra posibilidad es que se ilustren con ejemplos prácticos y se mencionen las soluciones tecnológicas existentes en el Estado promulgante en un momento dado que cumplan esos requisitos y la manera en que lo hagan. Otro criterio sería que, si la entidad adjudicadora decidiera utilizar comunicaciones no consignadas sobre papel, se exigiera emplear medios especiales de comunicación que cumplieran esos requisitos de la Ley Modelo, a la luz de las condiciones imperantes en el Estado promulgante en un momento dado.

2. Los reglamentos deberían establecer reglas claras en lo que respecta a los requisitos de que la información “conste por escrito” o “esté firmada”, o de “autenticidad”, “seguridad”, “integridad” y “confidencialidad” de las comunicaciones y, cuando fuera necesario, deberían crearse equivalentes funcionales del contexto de las comunicaciones no consignadas sobre papel. También se deberían proporcionar soluciones jurídicas encaminadas a lograr el buen funcionamiento, la confiabilidad, la localización y la verificación de la información generada en el proceso de adjudicación y a garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad de esa información según proceda. Hay que tener cuidado de no vincular los requisitos jurídicos a un determinado nivel de desarrollo técnico y de no imponer medidas de seguridad más estrictas de las que se aplicarían en un contexto de comunicaciones consignadas sobre papel, ya que esas medidas pueden disuadir a los proveedores y contratistas de participar en el proceso en un contexto que no sea el de la documentación escrita.

3. Otras cuestiones para tener especialmente en cuenta en el reglamento son: a) el alcance de las excepciones al requisito de forma previstas en el párrafo 2 del artículo y la aplicación práctica de las disposiciones, y b) los aspectos relacionados con la utilización de más de una forma y de un medio para comunicar información en un proceso de adjudicación en particular.

4. Como se indica en la Guía¹⁰, hay otros aspectos y ámbitos jurídicos que son pertinentes para el artículo 7, en particular los relacionados con el comercio electrónico, la gestión de los expedientes, las actuaciones judiciales, la competencia, la protección y la confidencialidad de los datos, la propiedad intelectual y los derechos de autor. Además, la fiabilidad del procedimiento de contratación pública debería regularse como parte de un marco general de buena gobernanza que abarcara cuestiones de personal, de gestión y de administración de la entidad adjudicadora y del sector público en su conjunto.

¹⁰ Párr. 13 del comentario sobre el artículo 7.

Artículo 8. Participación de proveedores y contratistas [\[hiperenlace**\]](#)**

1. El reglamento de la contratación pública o alguna otra norma aplicable del Estado promulgante debe establecer las condiciones excepcionales en que la entidad adjudicadora puede limitar la participación de ciertas categorías de proveedores o contratistas en el proceso de adjudicación.
2. Como se observa en la Guía¹¹, puede decidirse limitar la participación en el proceso en diferentes situaciones. Como se indicó en la sección II.A del presente documento, esa clase de situaciones puede surgir de resultados de políticas socioeconómicas del Estado (por ejemplo, programas de reservas de fondos para las pequeñas y medianas empresas o para entidades de zonas desfavorecidas). Hay otras cuestiones de interés para el Estado, como la seguridad pública, que pueden justificar esas restricciones, por ejemplo, la aplicación de regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por consiguiente, la aplicación del artículo no daría lugar necesariamente a la limitación de la participación por razones de nacionalidad (como en la contratación nacional). El reglamento debería regular la variedad de situaciones que puede abarcar este artículo, como se explica en la Guía.
3. Como también se observa en la Guía¹², al formular políticas que comprendan medidas excepcionales como las previstas en el artículo 8, el Estado promulgante debe considerar sus consecuencias a la luz de sus obligaciones internacionales, teniendo en cuenta que toda restricción de la participación de proveedores o contratistas en el proceso de adjudicación entraña el peligro de transgredir los compromisos de libre comercio de los Estados en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes, entre ellos el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC)¹³.
4. El reglamento puede contener un modelo de la declaración que habrá de formular la entidad adjudicadora con arreglo al párrafo 3 del artículo. También se puede precisar el plazo dentro del cual la entidad adjudicadora dará a conocer a cualquier persona que lo solicite las razones por las que haya decidido limitar la participación de proveedores o contratistas en un proceso de contratación conforme a lo previsto en el párrafo 5 del artículo.
5. En el contexto de los párrafos 4 y 5 del artículo, el reglamento puede imponer a la entidad adjudicadora la obligación de sustanciar con argumentos jurídicos las razones y circunstancias en que se basó para adoptar la decisión de restringir la participación.

¹¹ Párr. 2 del comentario sobre el artículo 8.

¹² Párr. 7 del comentario sobre el artículo 8.

¹³ El Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, de alcance plurilateral, negociado paralelamente a la Ronda Uruguay en 1994, que entró en vigor el 1 de enero de 1996. El 15 de diciembre de 2011 se llegó a un acuerdo sobre los resultados de la renegociación de ese instrumento. Esa decisión política fue confirmada el 30 de marzo de 2012 mediante la adopción oficial de la Decisión sobre los resultados de las negociaciones celebradas de conformidad con el párrafo 7 del artículo XXIV del Acuerdo sobre Contratación Pública (GPA/113). Ambos textos figuran en http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/negotiations_s.htm.

Artículo 9. Idoneidad exigible de todo proveedor o contratista [\[hiperenlace**\]](#)**

1. Siempre y cuando no lo hiciera ya alguna otra norma aplicable del Estado promulgante, los reglamentos deben establecer las normas éticas y de otra índole aplicables en ese Estado que sean apropiadas y pertinentes en las circunstancias de las diversas clases de contratación pública (véanse el apartado 2 b) del artículo y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#)).
2. También se deberían precisar las pruebas documentales apropiadas u otra información que pudiera exigir la entidad adjudicadora para determinar la idoneidad de los proveedores o contratistas (véanse el párrafo 3 del artículo y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#)). Esas pruebas documentales podrán consistir en informes anuales verificados (para demostrar que disponen de recursos), inventarios de equipo y otros medios materiales, licencias que les autoricen a desarrollar determinados tipos de actividades y certificados de conformidad con las normas aplicables y que confirmen su situación jurídica.
3. Además, el reglamento puede autorizar concretamente una autodeclaración de los proveedores o contratistas en el sentido de que están cualificados para participar en determinado proceso de contratación. En ese caso, se deberían precisar las situaciones en que bastaría con esa clase de autodeclaraciones. Por ejemplo, tal vez sea suficiente atenerse a ese tipo de declaración al comienzo de subastas electrónicas inversas sencillas de carácter exclusivo, a condición de que se prevea proceder a la debida comprobación del cumplimiento de los criterios de calificación aplicables por parte del proveedor o contratista ganador después de la subasta.
4. En algunos países, los requisitos de idoneidad uniformes normalmente exigibles se enuncian en el reglamento de la contratación pública, al que simplemente remitirán los documentos de precalificación o preselección y el pliego de condiciones. En aras de la transparencia y la igualdad de trato, la Ley Modelo exige que todos esos requisitos figuren en los documentos pertinentes (véanse el párrafo 4 del artículo y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#)); no obstante, podrán cumplirse los objetivos de política del párrafo 4 si los documentos remiten a los requisitos de idoneidad contenidos en fuentes de derecho transparentes y de fácil acceso (por ejemplo, mediante el uso de [hiperenlaces](#)). El reglamento debe autorizar ese método si resulta apropiado en el Estado promulgante.
5. El reglamento debe autorizar o exigir el uso de cualesquiera criterios de idoneidad, requisitos o procedimientos que no sean objetivamente justificables y que discriminen contra o entre proveedores o contratistas a fin de que los pueda emplear la entidad adjudicadora al evaluar la idoneidad del proveedor o contratista (véanse el párrafo 6 del artículo conjuntamente con el artículo 8 (véase el examen de este último que se hace más arriba) y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#)). También pueden darse ejemplos de otros requisitos impuestos en la práctica por las entidades adjudicadoras que pueden distorsionar o restringir, de manera intencional o inadvertida, la participación de proveedores o contratistas en el proceso de adjudicación y que, en consecuencia, deberían evitarse.
6. El reglamento puede contener ejemplos de información con inexactitudes u omisiones graves que daría lugar a que la entidad adjudicadora descalificara al proveedor o contratista que la haya presentado (véanse el apartado 8 b) del artículo y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#)).

7. El reglamento puede restringir la aplicación del apartado 8 d) disponiendo que en la mayoría de los contratos (salvo, tal vez, los más complejos, que exijan una laboriosa negociación en varias etapas) la reconfirmación de la idoneidad de los proveedores o contratistas que hayan superado la precalificación en una etapa posterior del proceso de adjudicación tenga lugar únicamente con respecto al proveedor o contratista que haya presentado la oferta ganadora (véanse el apartado 8 d) del artículo y el comentario correspondiente **[**hiperenlaces**]**).

8. Hay otras ramas del derecho que son pertinentes para la aplicación del artículo 9, entre ellas las relativas al régimen de la insolvencia, el derecho tributario y la legalización, así como al derecho de las sociedades mercantiles y el derecho penal. El cumplimiento de otras normas aplicables en el Estado promulgante, al que se hace referencia en el apartado 2 b) del artículo, puede entrañar acreditaciones de seguridad, consideraciones ambientales, normas internacionales de derecho laboral y de derechos humanos y cuestiones de sostenibilidad ajenas al régimen de la contratación pública. En consecuencia, debe garantizarse la compatibilidad del reglamento de la contratación pública con las reglamentaciones que puedan existir en esas otras ramas del derecho.

Artículo 10. Reglas concernientes a la descripción del objeto del contrato adjudicable y a las condiciones de ese contrato o del acuerdo marco
[hiperenlace**]**

1. El reglamento debe precisar las situaciones en que no sería posible hacer una descripción detallada del objeto del contrato adjudicable al comienzo de un proceso de adjudicación y en que, por consiguiente, la entidad adjudicadora estaría facultada para proporcionar, en cambio, los requisitos mínimos (por ejemplo, en los procedimientos de solicitud de propuestas con diálogo y de acuerdo marco) (véanse el apartado 1 b) y el comentario correspondiente **[**hiperenlaces**]**).

2. El reglamento debe autorizar o exigir el uso de cualesquiera criterios, requisitos o procedimientos que puedan restringir la participación de proveedores o contratistas en el proceso de adjudicación, o su acceso a este, a fin de que los pueda emplear la entidad adjudicadora al describir el objeto del contrato adjudicable y/o examinar las ofertas (véanse el párrafo 2 del artículo conjuntamente con el artículo 8 (véase el examen acerca de este último que se hace más arriba) y el comentario correspondiente **[**hiperenlaces**]**). También pueden darse ejemplos de otros requisitos impuestos en la práctica por las entidades adjudicadoras que pueden distorsionar o restringir, de manera intencional o inadvertida, la participación de proveedores o contratistas en el proceso de adjudicación y que, en consecuencia, deberían evitarse.

3. Sería conveniente que se determinara en qué medida la entidad adjudicadora podrá utilizar a su discreción marcas registradas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos, un origen específico o determinado productor en la descripción del objeto del contrato adjudicable (véanse el párrafo 4 del artículo y el comentario correspondiente **[**hiperenlaces**]**). Se deberá: a) examinar las circunstancias muy especiales descritas en el párrafo 4 del artículo que justifiquen la utilización de aquellos (si no hubiera otro medio suficientemente preciso o inteligible de describir las características del objeto del contrato adjudicable); b) como regla general, exigir una descripción basada en el producto; c) destacar la necesidad de describir los rasgos salientes del objeto del contrato adjudicable cuando deba utilizarse la

descripción basada en los insumos, y d) exigir que se incluya la expresión “o equivalente” en la descripción cuando no se pueda evitar o sea conveniente hacer referencia a la marca registrada o el nombre comercial, la patente, el diseño o tipo, el origen específico o el productor para que los proveedores o contratistas comprendan mejor las necesidades de la entidad adjudicadora. Como se observa en la Guía, cuando existe una norma industrial de uso generalizado (que puede verse reflejada en cláusulas y términos comerciales normalizados), el hecho de que se permita utilizar un nombre comercial o una marca registrada, en lugar de una muy larga descripción técnica, puede ayudar a los proveedores o contratistas a comprender más las necesidades de la entidad adjudicadora. No obstante, en esos casos, a manera de salvaguardia, habrá que comprobar la voluntad de la entidad adjudicadora de aceptar elementos equivalentes e impartir orientación acerca de la manera en que los proveedores o contratistas deberán demostrar la equivalencia y la manera de actuar con objetividad al respecto¹⁴. En consecuencia, deberían determinarse modos de demostrar y evaluar la equivalencia y se debería exigir a la entidad adjudicadora que aceptara elementos equivalentes.

4. El reglamento de la contratación pública deberá establecer rasgos, requisitos, símbolos y términos normalizados para que utilice la entidad adjudicadora al formular la descripción del objeto del contrato adjudicable o remitirse a la fuente en que puedan encontrarse esos rasgos, requisitos, símbolos y términos normalizados. Lo mismo rige con respecto a las cláusulas y condiciones comerciales normalizadas que utilizará la entidad adjudicadora al formular las cláusulas y condiciones del contrato o del acuerdo marco y demás aspectos pertinentes de los diversos documentos conexos: deberían establecerse en el reglamento o este debería remitirse a la fuente en que pudieran encontrarse. (Véanse el párrafo 5 del artículo y el comentario correspondiente **[**hiperenlaces**]**.)

Artículo 11. Reglas concernientes a los criterios y procedimientos de evaluación **[**hiperenlace**]**

1. El reglamento puede contener una lista más amplia y exhaustiva de criterios de evaluación que la que figura en el párrafo 2 del artículo. No obstante, debería evitarse establecer una lista exhaustiva de criterios o exigir que se utilizaran criterios especiales o un grupo de criterios, salvo el del precio, ya que no todos los criterios de evaluación se aplicarían en todas las situaciones y no sería posible proporcionar una lista exhaustiva de criterios para todos los tipos de contratación, independientemente de la amplitud con que estuviesen redactados. El enfoque de la Ley Modelo, como se indica en la Guía, es facultar a la entidad adjudicadora para aplicar criterios de evaluación que no estén comprendidos en las categorías amplias enumeradas en el párrafo 2, siempre y cuando cumplan el requisito enunciado en el párrafo 1 del artículo, es decir, que guarden relación con el objeto del contrato adjudicable¹⁵. Sin embargo, el reglamento puede exigir que las autoridades competentes dicten normas o directrices, o ambas, para ayudar a las entidades adjudicadoras a formular criterios de evaluación apropiados y pertinentes.

2. El reglamento de la contratación pública debería abordar situaciones en las que fuera pertinente evaluar la experiencia, la fiabilidad y la competencia profesional y

¹⁴ Párr. 5 del comentario sobre el artículo 10.

¹⁵ Párr. 3 del comentario sobre el artículo 11.

de gestión del proveedor o contratista, así como del personal que interviniera en la entrega del objeto del contrato adjudicado (véanse el apartado 2 c) del artículo y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#)). Eso procedería normalmente en el contexto de procedimientos de solicitud de propuestas, que se han utilizado tradicionalmente para contratar “servicios de índole intelectual” (por ejemplo, servicios de arquitectura, jurídicos, médicos o de ingeniería). En esa clase de contratación pública el costo no es un criterio de evaluación importante. En cambio, se hace hincapié en la experiencia del proveedor de servicios y en la confianza que inspire con respecto a la tarea de que se trate, en su conocimiento del tema objeto de la consultoría y la metodología propuesta, en la competencia profesional y de gestión del personal sustantivo que vaya a prestar el servicio, en la transmisión de conocimientos, si eso es pertinente para el contrato adjudicable, o es parte integrante de los términos y condiciones contractuales, y, cuando proceda, el grado de participación de nacionales en la dotación de personal sustantivo encargado de prestar los servicios.

3. Se debe aclarar que esos criterios de evaluación pueden sumarse a los requisitos mínimos de aptitudes y experiencia mencionados como criterios de idoneidad en el artículo 9 [\[**hiperenlace**\]](#). Si bien en el artículo 9 se faculta a la entidad adjudicadora para rechazar toda propuesta de un proveedor o contratista que no reúna los requisitos mínimos de aptitudes y experiencia, aquella podrá evaluar las aptitudes y la experiencia de los proveedores o contratistas idóneos admitidos a la etapa de diálogo: podrá ponderar, por ejemplo, la experiencia de un proveedor de servicios frente a los demás y, a partir de esa comparación, podrá confiar, en mayor o menor medida, en la capacidad de un proveedor o contratista en particular, y no de otro, para ejecutar el proyecto. Por consiguiente, en el reglamento debería explicarse la manera de emplear esos criterios como normas mínimas para determinar la idoneidad de los proveedores o contratistas con arreglo al artículo 9 de la Ley Modelo [\[**hiperenlace**\]](#) y de utilizarlos, por ejemplo, con arreglo a los artículos 11 y 49 [\[**hiperenlaces**\]](#), lo que daría lugar a que la entidad adjudicadora evaluara esos criterios de manera competitiva.

4. De no estar previsto en otras normas jurídicas de los Estados promulgantes, el reglamento de la contratación pública debe establecer todo criterio excepcional que la entidad adjudicadora esté autorizada u obligada a tener en cuenta para evaluar las ofertas, criterio este que, en circunstancias normales, no guardará relación con el objeto del contrato adjudicable y, por consiguiente, muy probablemente no sería un criterio de evaluación permitido conforme al párrafo 2 del artículo (véanse el apartado 3 a) del artículo y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#)). Véase también lo expuesto en la sección II.A del presente documento, bajo el título “Las políticas socioeconómicas en la contratación” [\[**hiperenlace**\]](#)). Al determinar esos criterios debería evitarse toda remisión a categorías amplias, como las consideraciones relacionadas con el medio ambiente, ya que podría existir superposición con los criterios previstos en el párrafo 2 del artículo. Por ejemplo, las normas ambientales para la producción del objeto del contrato están relacionadas con ese objeto y, por lo tanto, pueden incluirse entre los criterios de evaluación con arreglo al párrafo 2; para eso no se necesita autorización en virtud de reglamentación ni ley alguna. Hay otras consideraciones ambientales que no están tan relacionadas, pero que puede ser necesario tener en cuenta si así se dispone o autoriza por ley en el Estado promulgante.

5. El reglamento también debería disponer la manera de utilizar los criterios previstos en el apartado 3 a) en cada proceso de adjudicación para lograr que se apliquen de manera objetiva y transparente. Habida cuenta de que la aplicación de normas ambientales, en particular, puede dar lugar a la exclusión de proveedores o contratistas extranjeros (si, por ejemplo, las normas nacionales son más estrictas que las que rigen en otros Estados), se debería recomendar o exigir que se impartiera orientación especial sobre el empleo de normas ambientales para garantizar que las entidades adjudicadoras pudieran aplicarlas sin correr el riesgo de enfrentarse a costosos procedimientos de impugnación.

6. De no estar previsto en otras normas jurídicas de los Estados promulgantes, los reglamentos de la contratación pública deben autorizar o exigir que, al evaluar las ofertas, se otorgue todo margen de preferencia aplicable, u otro tipo de preferencia, a los proveedores o contratistas nacionales o a los bienes de origen interno (véanse el apartado 3 b) del artículo y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#). Véase también lo expuesto en la sección II.A del presente documento, bajo el título “Las políticas socioeconómicas en la contratación” [\[**hiperenlace**\]](#)). También deberían establecer criterios para determinar cuándo un proveedor o contratista es “nacional” y un bien es “de origen interno” (por ejemplo, que tenga un contenido mínimo de origen interno o de valor añadido en el país). Al respecto, las disposiciones del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC sobre los programas de compensaciones y de precios preferenciales, de que disponen los países en desarrollo como medidas de transición negociadas, pueden ayudar a los Estados a comprender cómo se han aplicado en la práctica los conceptos de proveedores o contratistas “nacionales” y de “contenido local”.

7. Además, se debería establecer el monto del margen de preferencia, que podría ser diferente para las diversas clases de objetos de los contratos adjudicables (bienes, construcción y servicios). También debe proporcionarse un método y reglas concernientes al cálculo y la aplicación del margen de preferencia. (En diversas fuentes de información de dominio público, entre ellas las del Banco Mundial, figuran ejemplos de la aplicación de márgenes de preferencia en la práctica.) En ese método puede preverse la aplicación de un margen de preferencia al precio o a los factores de calidad exclusivamente, o a la clasificación global de la oferta, cuando proceda; el Estado promulgante deseará decidir la manera de equilibrar las consideraciones sobre la calidad y el cumplimiento de las políticas socioeconómicas. Como se indica en la Guía¹⁶, habría que sopesar cuidadosamente el efecto acumulado de la aplicación de criterios socioeconómicos y márgenes de preferencia y los riesgos de duplicación inadvertida.

8. El reglamento debe contener una lista ilustrativa de situaciones en las que expresar en unidades monetarias todos los criterios de evaluación distintos del precio no sería viable o procedente, como en la solicitud de propuestas con diálogo (artículo 49 de la Ley Modelo [\[**hiperenlace**\]](#)). También debe enunciar la manera de cuantificar en unidades monetarias los criterios de evaluación que no sean el precio cuando resulte viable. (Véanse el párrafo 4 del artículo y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#).) Además, debe abordar las situaciones en que la entidad adjudicadora pueda enumerar los criterios de evaluación en orden descendente de importancia (véanse el apartado 5 c) del artículo y el comentario

¹⁶ Párr. 9 del comentario sobre el artículo 11.

correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#)), como en el caso del procedimiento de solicitud de propuestas con diálogo, previsto en el artículo 49 de la Ley Modelo [\[**hiperenlace**\]](#).

Artículo 12. Reglas relativas a la estimación del valor del contrato adjudicable
[\[hiperenlace**\]](#)**

En el reglamento de la contratación pública deberían explicarse las reglas relativas a la estimación del valor del contrato adjudicable. En particular, se debería aclarar la manera de acumular una serie de contratos de poca cuantía a lo largo de un período determinado a los efectos de tener en cuenta los umbrales correspondientes. También se deberían prever salvaguardias esenciales para evitar que se fraccionara artificialmente el objeto del contrato adjudicable, por ejemplo, a fin de justificar el empleo de la licitación restringida invocando el apartado b) del artículo 29.1 [\[**hiperenlace**\]](#), es decir, con el argumento de que el tiempo y los gastos que supondría el examen y la evaluación de un gran número de ofertas resultarían desproporcionados en relación con el valor del objeto del contrato adjudicable.

Artículo 13. Reglas relativas al idioma de la documentación [\[hiperenlace**\]](#)**

1. En los Estados en que el pliego de condiciones por lo general se publique en más de un idioma, el reglamento de la contratación pública, a menos que ya esté previsto en el régimen correspondiente del Estado promulgante, debería contener una regla en el sentido de que el proveedor o contratista pudiera basar sus derechos y obligaciones en cualquiera de las versiones del documento. También puede exigirse a la entidad adjudicadora que aclare en el pliego de condiciones que ambas o todas las versiones son igualmente válidas, o que una de ellas prevalecerá en caso de incompatibilidad.

2. Si se conserva el texto que figura entre corchetes en el primer párrafo del artículo, el reglamento debería enunciar las excepciones a la regla general de publicar los documentos preparados por la entidad adjudicadora en el procedimiento de contratación en un idioma de uso corriente en el comercio internacional. Esas excepciones abarcan las circunstancias mencionadas en el artículo 33.4 [\[**hiperenlace**\]](#): en la contratación nacional (véase el comentario sobre el artículo 8 [\[**hiperenlace**\]](#)) y en los procedimientos de contratación en que la entidad adjudicadora determine que, en vista del poca cuantía del objeto del contrato adjudicable, es probable que únicamente los proveedores y contratistas nacionales tengan interés en presentar ofertas. (Véase en la sección II.C del presente documento el examen de las cuestiones que ha de abordar el reglamento de la contratación pública en el contexto de los contratos de poca cuantía [\[**hiperenlace**\]](#).)

Artículo 14. Reglas sobre el modo, el lugar y el plazo para la presentación de solicitudes de precalificación, de preselección o de ofertas [\[hiperenlace**\]](#)**

1. El reglamento de la contratación pública puede prever las posibles consecuencias jurídicas del incumplimiento por los contratistas o proveedores de los requisitos establecidos por la entidad adjudicadora con respecto al modo, el lugar y el plazo de presentación de solicitudes de precalificación, de preselección o de ofertas (por ejemplo, la entidad adjudicadora debe devolver las ofertas que se presenten una vez vencido el plazo o que no cumplan de otro modo los requisitos

necesarios (véanse, por ejemplo, el artículo 40.3 y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#))).

2. Se debe exigir a la entidad adjudicadora que se cerciore de que toda modificación de la información prevista en el artículo se ponga en conocimiento de cada uno de los proveedores o contratistas a los que inicialmente se hayan entregado los documentos de precalificación o de preselección o el pliego de condiciones (véanse el párrafo 5 del artículo y los artículos 15.2 y 18.6, así como el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#)). Si los documentos se entregaron a un grupo desconocido de proveedores o contratistas (por ejemplo, se facilitaron en un sitio web), debe exigirse que la información relativa a las modificaciones figure, como mínimo, en el mismo lugar en que pudo obtenerse por vía electrónica.

3. Debe establecerse el plazo mínimo que la entidad adjudicadora ha de conceder a los proveedores o contratistas (en particular si sus compromisos internacionales le obligan a hacerlo) para que preparen sus solicitudes u ofertas. El plazo debe establecerse a la luz de cada método de contratación, el medio de comunicación empleado y el carácter nacional o internacional de la contratación. En la contratación internacional, y en relación con contratos complejos, ese período debe ser suficiente como para que los proveedores o contratistas tengan tiempo de preparar sus solicitudes u ofertas. La decisión última acerca del plazo, en el contexto de cada contrato adjudicable, se deja en manos de la entidad adjudicadora, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, por ejemplo, la complejidad del contrato, el volumen de la subcontratación prevista y el tiempo necesario para transmitir las solicitudes u ofertas.

4. El reglamento debería prever las situaciones en que la prórroga del plazo estipulado inicialmente fuera imperativa y en que estuviese permitida y fuese conveniente. La Ley Modelo dispone que la entidad adjudicadora prorrogue el plazo: a) cuando se entreguen aclaraciones o modificaciones, o actas de las reuniones de proveedores o contratistas, poco antes de que expire el plazo para la presentación de ofertas, y b) si, a raíz de una modificación de la información publicada acerca de la contratación al comienzo de esta, esa información pierde su exactitud de fondo (véanse el artículo 15.3 y el comentario correspondiente [\[**hiperenlaces**\]](#)). En otros casos, la prórroga del plazo es optativa. Para mitigar el riesgo de que la entidad adjudicadora abuse de esa facultad discrecional, el reglamento debería establecer algunas medidas de control. Por ejemplo, en el contexto del párrafo 4 del artículo podrían examinarse las “circunstancias ajenas a la voluntad [del proveedor o contratista]” que impedirían a uno o más proveedores o contratistas presentar sus solicitudes u ofertas a tiempo, la manera de demostrar esas circunstancias y la respuesta que ha de dar la entidad adjudicadora automáticamente en esas situaciones. Si bien debe promoverse la flexibilidad, esas medidas mínimas de control ayudarían a mitigar los riesgos de favoritismo.

5. Se puede indicar la conveniencia de prorrogar el plazo, en particular, en situaciones en las que la entidad adjudicadora esté expuesta a problemas considerables si no lo prorroga, por ejemplo, en los casos de averías en su sistema de comunicaciones. También deberían regularse otros aspectos relacionados con las averías de los sistemas de comunicaciones y la distribución de riesgos.

Artículo 15. Aclaraciones y modificaciones del pliego de condiciones**[**hiperenlace**]**

1. El reglamento de la contratación pública debe regular la aplicación del artículo en situaciones en que el pliego de condiciones se haya entregado a un grupo desconocido de proveedores o contratistas (por ejemplo, si se ha facilitado en un sitio web de dominio público). Se debería disponer que la obligación de la entidad adjudicadora de informar a cada uno de los proveedores o contratistas de todas las aclaraciones y modificaciones del pliego de condiciones se aplicara en la medida en que tuviera conocimiento de su identidad. Si le son desconocidos, las aclaraciones y modificaciones deben figurar, como mínimo, en el lugar en que el documento se haya facilitado electrónicamente. En consecuencia, el reglamento debe dejar claro que la entidad adjudicadora debe adoptar medidas activas; no basta con dar acceso a las aclaraciones o modificaciones a los proveedores o contratistas que lo soliciten, ya que estos no dispondrían de ningún medio para enterarse de que se hubiera hecho una aclaración o modificación.
2. El reglamento también debe exigir que la entidad adjudicadora adopte medidas urgentes con arreglo a este artículo para que los proveedores o contratistas puedan tener en cuenta las aclaraciones y modificaciones con tiempo suficiente antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas.
3. Además, se debe abordar el concepto de que la información “pierde su exactitud de fondo”, mencionado en el párrafo 3 del artículo, y distinguirlo del concepto de “modificación de fondo” de la contratación. Mientras en el primer caso es necesario publicar la modificación de la información en el mismo lugar en que apareció la información original y prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, en el segundo es preciso cancelar el procedimiento y comenzar un nuevo proceso de contratación. Ambos son conceptos liminales. Si, a raíz de las modificaciones, la información se volvió suficientemente inexacta como para comprometer la integridad de la competencia comercial y del proceso de adjudicación, cabe decir que la información perdió su exactitud de fondo. Si de resultados de esas modificaciones se ve afectado el grupo de posibles proveedores o contratistas (por ejemplo, si se ha pasado del soporte de papel al soporte electrónico para presentar las ofertas, en sociedades en las que los medios electrónicos de comunicación no están muy extendidos), cabe concluir que se ha producido una “modificación de fondo” en la contratación. También es muy probable que se produzca una de esas modificaciones “de fondo” cuando, a raíz de una aclaración o modificación del pliego de condiciones original, el objeto del contrato adjudicable haya cambiado tanto que los documentos originales ya no den a conocer a los posibles proveedores o contratistas los verdaderos requisitos de la entidad adjudicadora.
4. En el contexto del párrafo 4 del artículo, el reglamento debería aclarar que las disposiciones no impiden que durante la reunión de proveedores o contratistas la entidad adjudicadora mencione las solicitudes de aclaración del pliego de condiciones que se le hayan presentado antes de la reunión o durante ella y las respuestas que haya dado. En todos los casos regirá la obligación de respetar el anonimato de quien haya dado origen a la solicitud.

Artículo 16. Aclaración de los datos de calificación y de las ofertas**[**hiperenlace**]**

1. En el reglamento de la contratación pública debe hacerse una distinción entre este artículo y el anterior: si bien en el artículo anterior las aclaraciones son solicitadas por los proveedores o contratistas, en este las solicita la entidad adjudicadora. También deberían aclararse las diferencias entre el procedimiento de aclaración previsto en este artículo y las negociaciones (en el artículo se prohíben expresamente las negociaciones entre la entidad adjudicadora y un proveedor o contratista respecto de los datos de calificación o de las ofertas, salvo las presentadas con arreglo a los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley Modelo (véanse los párrafos 4 y 5 del artículo).

2. Se deberían establecer determinados momentos en los que podría plantearse la necesidad de hacer aclaraciones acerca de los datos de calificación o de las ofertas en los diversos métodos de contratación. También debería precisarse a cuáles de los métodos de contratación no se aplicarían algunas de las disposiciones del artículo. Por ejemplo, en el párrafo 2 se exige a la entidad adjudicadora que rectifique los errores puramente aritméticos que se descubran durante el examen de las ofertas. Sin embargo, eso no rige para algunos métodos de contratación, como el de solicitud de cotizaciones, en que estaría prohibido rectificar los errores aritméticos con arreglo al artículo 46.2 **[**hiperenlace**]**, y el de solicitud de propuestas con negociación consecutiva, en que eso sencillamente carecería de importancia, dado que los aspectos financieros de las ofertas se concretan durante las negociaciones. Tampoco regiría en la etapa de subasta en el caso de las subastas electrónicas inversas, en que los errores puramente aritméticos pueden dar lugar al rechazo automático por parte del sistema de la oferta que los contiene o a la clausura de la subasta, conforme al artículo 56.5 **[**hiperenlace**]**.

3. Se deberían dar ejemplos de las clases de aclaraciones previstas en el artículo. En particular, deberían mencionarse los riesgos de cambios sustantivos que se pueden plantear de resultados de una solicitud de aclaraciones o de la corrección de errores aritméticos, esta última, por lo demás, prohibida en virtud del artículo. Sería conveniente hacer una lista ilustrativa de los cambios que están prohibidos (en este contexto, en el artículo se mencionan cambios por los que un proveedor o contratista no calificado pase a estar calificado, o por los que una oferta no conforme pase a ser conforme, o que den lugar a la modificación del precio).

4. El reglamento debería disponer garantías procesales para mitigar el riesgo de que se aplicaran prácticas discriminatorias, por ejemplo, exigiendo a la entidad adjudicadora que hiciera constar todo error aritmético constatado durante el proceso de examen y evaluación y las medidas adoptadas al respecto.

5. Debería regularse la manera de solicitar aclaraciones con arreglo al artículo recurriendo a los procedimientos de investigación de las ofertas anormalmente bajas previstos en el artículo 20 **[**hiperenlace**]**. Debe exigirse que las actuaciones consten por escrito, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Modelo **[**hiperenlace**]**.

Artículo 17. Garantía de la oferta **[hiperenlace**]****

1. El reglamento de la contratación pública debería determinar cuáles son los casos que justificarían la solicitud de garantía de la oferta y dar ejemplos de casos

en los que esa garantía podría considerarse una salvaguardia excesiva por parte de la entidad adjudicadora¹⁷. Debería explicarse que en algunos métodos de contratación hay circunstancias que por sí mismas ofrecen la garantía necesaria para la entidad adjudicadora, por ejemplo, en el caso de las subastas electrónicas inversas. El valor relativo del contrato también puede indicar la conveniencia de promover otra clase de medidas para lograr la disciplina que corresponde en las licitaciones. Se pueden dar ejemplos de distintas opciones que pueden considerarse en lugar de una garantía, entre ellas, exigir que se firme una declaración por la que se garantice la oferta¹⁸, así como de casos en los que las ventajas de exigir garantía pueden ser ilusorias, por ejemplo, en los procesos de solicitud de propuestas con diálogo o en las subastas electrónicas inversas, en que no es posible obligar a los proveedores o contratistas a permanecer en el proceso de diálogo o de licitación (por ejemplo, en las subastas electrónicas inversas no puede obligarse a los concursantes a modificar ningún aspecto de sus ofertas, y estos pueden sencillamente abstenerse de presentarlas), de manera que la garantía de la oferta, de hecho, no tendría valor o, en el mejor de los casos, no sería eficaz en función del costo.

2. En los casos en que puede justificarse exigir una garantía de la oferta, debería establecerse la forma en que se aplicarían los requisitos en la práctica y sus repercusiones en el proceso de licitación, en particular en el precio de la oferta. También debe explicarse que en algunos métodos de contratación puede llegar un momento en especial en el que cabe exigir una garantía. Por ejemplo, en la licitación en dos etapas eso se hará en el contexto de la presentación de las ofertas definitivas, y no de las iniciales.

3. De ser procedente, el reglamento debería remitirse a toda ley del Estado promulgante que prohibiera a la entidad adjudicadora aceptar una garantía de la oferta que no fuera emitida por un otorgante de ese Estado. Debe exigir a la entidad adjudicadora que adopte medidas urgentes con arreglo a este artículo.

Artículo 18. Procedimiento de precalificación [\[hiperenlace**\]](#)**

El reglamento de la contratación pública debe disponer el lugar en que ha de publicarse la convocatoria a precalificación (la “gaceta oficial” o un sitio web). Como se explicó en la sección II.C del presente documento en el contexto de los contratos de poca cuantía, deben darse detalles acerca de la manera de interpretar lo que se entiende por “contrato de poca cuantía” a efectos de exonerar del requisito de publicación internacional a la convocatoria a precalificación para la adjudicación del contrato. En ese contexto, también debería explicarse que el poca cuantía del contrato, por sí solo, no justifica que se excluya la participación de proveedores o contratistas internacionales (a diferencia de lo que ocurre con la contratación nacional, conforme al artículo 8 [\[**hiperenlace**\]](#)): los proveedores o contratistas internacionales pueden participar en una contratación que no se haya anunciado a nivel internacional si así lo desean, por ejemplo, respondiendo a un anuncio publicado internamente o en la Internet¹⁹.

¹⁷ Figura orientación al respecto en los párrs. 4 y 5 del comentario de la Guía sobre el artículo 17.

¹⁸ Véase el párr. 12 del comentario de la Guía sobre el artículo 17.

¹⁹ Al respecto, véanse los párrs. 5 y 6 del comentario de la Guía sobre el artículo 18.

Artículo 19. Cancelación de la contratación [\[hiperenlace**\]](#)**

El reglamento de la contratación pública debería impartir orientación detallada a las entidades adjudicadoras sobre el alcance de su facultad discrecional para cancelar el proceso de adjudicación y su posible responsabilidad, tanto en virtud del régimen de la contratación pública como de toda otra norma jurídica del Estado promulgante que prevea responsabilidad en relación con los actos administrativos.

Artículo 20. Rechazo de las ofertas anormalmente bajas [\[hiperenlace**\]](#)**

1. El reglamento de la contratación pública debe remitirse a toda ley aplicable que exija que la entidad adjudicadora rechace una oferta, por ejemplo, si se ha incurrido en un acto delictivo (como el blanqueo de capitales) o en una práctica ilícita (como la de no cumplir con el pago del salario mínimo o con obligaciones de la seguridad social, o si ha habido colusión), y, al hacerlo, se debe distinguir entre esos casos y los previstos en el artículo. También debe explicarse el concepto de oferta anormalmente baja, en particular en el contexto de la licitación internacional.
2. Además, debe reglamentarse el tipo de información que la entidad adjudicadora podrá pedir para justificar el precio ofrecido, a lo que se hace referencia en el artículo y en los párrafos 4 a 8 del comentario correspondiente de la Guía. Se podrá conceder flexibilidad para rechazar o aceptar la oferta anormalmente baja, en reconocimiento del carácter sumamente subjetivo inherente a la evaluación del riesgo de incumplimiento, o puede decidirse, en cambio, circunscribir la facultad discrecional para aceptar o rechazar esas ofertas.

Artículo 21. Exclusión de un proveedor o contratista del procedimiento de contratación por haber ofrecido algún incentivo o por gozar de alguna ventaja competitiva desleal o adolecer de algún conflicto de intereses [\[hiperenlace**\]](#)**

1. A efectos de precaverse del riesgo de que se cometan abusos al aplicar el artículo, el reglamento de la contratación pública debería ayudar a la entidad adjudicadora a determinar si existe o no un hecho que justifique la exclusión de un proveedor o contratista del procedimiento de contratación por haber ofrecido algún incentivo, por gozar de alguna ventaja competitiva desleal o por haber surgido algún conflicto de intereses.
2. La Ley Modelo no exige que se den definiciones de los conceptos enunciados en el artículo. Si el Estado promulgante decide definirlos, tal vez desee tener en cuenta las consideraciones planteadas en el comentario de la Guía sobre el artículo. Si en el Estado promulgante existen definiciones jurídicas de esos conceptos, debería exigirse que se dieran a conocer como parte de los textos jurídicos que rigen la contratación pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Modelo [\[**hiperenlace**\]](#). Si no hubiera definiciones, en el reglamento deberían darse ejemplos de lo que constituye y no constituye una práctica prevista en el artículo. Por ejemplo, debería prohibirse a los consultores que hubieran participado en la preparación del pliego de condiciones participar también en el proceso de adjudicación del contrato correspondiente. También convendría regular la participación de filiales en el mismo proceso de adjudicación. En algunos países se acostumbra establecer un límite mínimo para determinar lo que se considera un “incentivo”; se alienta a los Estados promulgantes que deseen adoptar ese criterio a asegurarse de que ese límite sea apropiado en las circunstancias de que se trate.

3. Muy probablemente habrá que remitirse a otras ramas del derecho del Estado promulgante, por ejemplo, a la legislación contra los monopolios, a fin de evitar confusiones innecesarias, incompatibilidades y apreciaciones incorrectas acerca de las políticas del Estado promulgante contra la corrupción.

Artículo 22. Aceptación de una oferta y entrada en vigor del contrato

[hiperenlace**]**

1. El reglamento de la contratación pública debe establecer la duración mínima de la moratoria. Para eso deben tenerse en cuenta varias consideraciones generales, entre ellas la repercusión que tendría la duración del período en los objetivos globales de la Ley Modelo. Si bien las repercusiones que tendría una moratoria prolongada en los gastos serían tenidas en cuenta por los proveedores o contratistas en el precio de su oferta y al decidir si participarían o no, el período deberá ser suficientemente largo como para que puedan presentarse recursos contra el proceso. Los Estados promulgantes tal vez deseen establecer más de una moratoria para los distintos tipos de contratación, teniendo en cuenta las dificultades que haya para determinar si se han cumplido o no las normas y procedimientos aplicables, pero deberían tener presente que puede ser inapropiado establecer períodos excesivamente prolongados en el contexto de las subastas electrónicas inversas y los acuerdos marco abiertos, que presuponen una pronta adjudicación y en los cuales la cantidad y complejidad de las cuestiones que pueden impugnarse son limitadas. En cambio, en los contratos de adquisición de infraestructura puede necesitarse un período más prolongado para considerar la situación. Puede ser conveniente expresar la duración de la moratoria en días hábiles o días civiles, dependiendo de la duración y de los feriados que haya. Cabe tener presente que el objetivo principal de la moratoria es dar a los proveedores o contratistas suficiente tiempo para decidir si impugnarán la decisión de la entidad adjudicadora de aceptar la oferta ganadora. Por consiguiente, la moratoria deberá ser tan breve como lo permitan las circunstancias, a efectos de no interferir indebidamente con el proceso de adjudicación en sí mismo. Si se presenta una impugnación, las disposiciones del capítulo VIII de la Ley Modelo regularían la suspensión del proceso y los demás recursos apropiados.

2. Deberían darse ejemplos de razones urgentes de interés público que pudieran servir de justificación para no aplicar la moratoria y se debería garantizar que fueran compatibles con las justificaciones para levantar la prohibición de hacer entrar en vigor el contrato adjudicado, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 **[**hiperenlace**]** y para levantar la suspensión automática, conforme a lo dispuesto en el artículo 67 **[**hiperenlace**]** (véase más adelante, en la sección X, el examen de estas cuestiones). Como se observó en la sección II.C del presente documento en relación con los contratos de poca cuantía, también debe considerarse la posibilidad de armonizar el límite que se establezca para exonerar a la contratación de poca cuantía de la aplicación de la moratoria, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 b) del artículo 22 **[**hiperenlace**]**, con otros límites, como los que justifiquen la exoneración de anunciar públicamente los contratos adjudicados (con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.2 **[**hiperenlace**]**) y el uso del procedimiento de solicitud de cotizaciones (con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.2 **[**hiperenlace**]**).

3. Se debería indicar la clase de circunstancias en las que podría exigirse un contrato escrito, teniendo en cuenta que un requisito de esa índole puede ser

particularmente gravoso para los proveedores o contratistas extranjeros, y si el Estado promulgante impone medidas para demostrar la autenticidad de la firma. De modo análogo, debería determinarse la clase de circunstancias en las que el contrato debería ser aprobado por otra autoridad antes de que entrara en vigor (por ejemplo, únicamente los contratos adjudicables que sobrepasaran un valor determinado).

4. Se debería impartir orientación para decidir la mejor manera de proceder cuando el concursante ganador no celebrara el contrato a su debido tiempo y se debería disponer la forma de evitar que se abusara del poder discrecional conferido a la entidad adjudicadora para cancelar la contratación o para adjudicar el contrato al concursante que hubiese presentado la siguiente oferta conforme. Al respecto, son pertinentes las consideraciones planteadas más adelante, en el contexto análogo de los artículos 43 y 57.

5. Puede ser conveniente que el reglamento regule las cuestiones vinculadas a la notificación con aclaraciones: aunque se mencione como opción de la entidad adjudicadora, en el reglamento puede hacerse hincapié en las ventajas que entraña esa clase de notificaciones, en particular en el contexto de los acuerdos marco, en que hay contrataciones reiteradas que pueden resultar beneficiadas si se mejoran las ofertas. Deberían establecerse garantías procesales mínimas y garantías de transparencia, en particular en lo que respecta a la necesidad de que en la notificación se respetara el carácter confidencial de la información comercial delicada²⁰.

Artículo 23. Anuncio público de los contratos adjudicados y de todo acuerdo marco concertado [\[hiperenlace**\]](#)**

1. El reglamento de la contratación pública debe disponer la manera de publicar la información prevista en el artículo²¹ y regular detalladamente la manera de hacer publicaciones periódicas de avisos de todos los contratos adjudicados en virtud del acuerdo marco.

2. Se fijará un límite monetario por debajo del cual ese requisito no sería aplicable. Como se observó en la sección II.C del presente documento, eso debe armonizarse con el trato que se conceda a la contratación de poca cuantía en el Estado promulgante. En ese contexto, cabría explicar que, si bien la exoneración de publicación prevista en el párrafo 2 abarca los contratos de poca cuantía adjudicados en virtud de un acuerdo marco, es muy improbable que abarque los acuerdos marco propiamente dichos, ya que el valor acumulado de los contratos que se adjudiquen con arreglo a un acuerdo marco probablemente excedería de la cuantía mínima establecida.

Artículo 24. Confidencialidad [\[hiperenlace**\]](#)**

1. El reglamento de la contratación pública debe establecer, si no una lista exhaustiva de la información prevista en el párrafo 1 del artículo, por lo menos las fuentes jurídicas de las que provenga, en particular precisar los conceptos de

²⁰ En los párrs. 23 a 27 del comentario de la Guía sobre el artículo 22 figura orientación sobre las cuestiones relativas a la notificación con aclaraciones.

²¹ En relación con las normas mínimas de publicación de esta clase de información, véase el comentario de la Guía sobre el artículo 5.

información que esté prohibido revelar en aras de intereses de seguridad esenciales del Estado promulgante y de información cuya divulgación pueda “menoscabar la libre competencia comercial”. Si esos conceptos no se regulan, la entidad adjudicadora puede interpretarlos en un sentido muy amplio para evitar la divulgación de cierta información alegando razones de confidencialidad. En otras ramas del derecho puede determinarse que cierta información es reservada y el reglamento puede remitirse a ellas; en otros casos, el propio reglamento debería limitar claramente el alcance de los conceptos pertinentes enunciados en el párrafo 1 del artículo.

2. Como se observó en la sección II.B del presente documento, el reglamento puede disponer las medidas que debería adoptar la entidad adjudicadora con respecto a los proveedores o contratistas y sus subcontratistas para proteger la información reservada en el contexto de una determinada contratación, además de las medidas de protección jurídica general previstas en el párrafo 1. También deberían explicarse las situaciones en que esas medidas podrían estar justificadas o ser imperativas debido al carácter delicado del objeto del contrato o por la existencia de información reservada aun cuando el objeto del contrato en sí no fuese de carácter delicado (por ejemplo, los casos en que se hiciera necesario garantizar el carácter confidencial de la información sobre un programa de entregas o sobre el lugar donde se hubieran de efectuar estas), o ambas cosas. Puede ser necesario que el reglamento se remita a otras ramas del derecho.

Artículo 25. Expediente del procedimiento de adjudicación [\[hiperenlace**\]](#)**

1. El reglamento de la contratación pública debería imponer obligaciones estrictas en materia de registro de la información con objeto de garantizar la exactitud y amplitud del expediente y, de esa manera, dar la posibilidad a los proveedores o contratistas que se sintieran perjudicados de entablar recursos y a los órganos competentes de realizar auditorías y controlar y supervisar el proceso de manera acertada y eficaz. Debe reglamentarse la forma en que ha de hacerse constar la información y los medios utilizados para hacerlo, el momento de introducir la información y los documentos en el expediente y el grado de divulgación de la información pertinente del expediente a los diversos grupos de personas interesadas en obtener acceso a este.

2. Se debería exigir a la entidad adjudicadora que diera rápido acceso a las personas autorizadas a las partes pertinentes del expediente, ya que aplazar la divulgación, por ejemplo, hasta que entrara en vigor el contrato adjudicado, privaría de un recurso eficaz a los proveedores o contratistas que se considerasen perjudicados. Dado que la revelación de cierta información (por ejemplo, información más detallada relativa al curso que se dará al proceso de adjudicación) puede ser impugnada por los proveedores o contratistas si consideran que menoscaba la libre competencia comercial y obra en detrimento de sus intereses comerciales legítimos, en algunas contrataciones especialmente delicadas el reglamento puede exigir a la entidad adjudicadora que dé aviso a los proveedores o contratistas en el pliego de condiciones de su intención de revelar partes del expediente relacionadas con el curso del proceso de adjudicación que son pertinentes para ellos.

3. Como se indicó anteriormente en el contexto del artículo 24, el reglamento debe establecer, si no una lista exhaustiva de la información prevista en el párrafo 4

del artículo, por lo menos las fuentes jurídicas de las que provenga, en particular precisar los conceptos de información que esté prohibido revelar en aras de intereses de seguridad esenciales del Estado promulgante y de información cuya divulgación pueda “menoscabar la libre competencia comercial”. La entidad adjudicadora puede interpretar esos conceptos en un sentido muy amplio para evitar la divulgación de cierta información del expediente alegando razones de confidencialidad. En otras ramas del derecho puede determinarse que cierta información es reservada y el reglamento puede remitirse a ellas; en otros casos, el propio reglamento debería limitar claramente el alcance de los conceptos pertinentes enunciados en el párrafo 4 del artículo.

4. El reglamento debe establecer toda la información que ha de incluirse en el expediente de la contratación, además de la enumerada expresamente en la propia ley (véase en este contexto el apartado w) del artículo 25.1 [\[**hiperenlace**\]](#)). Por ejemplo, puede exigir que se haga constar en el expediente documental del proceso adjudicatorio si se han presentado ofertas fuera de plazo y toda diferencia menor, error y omisión que se haya constatado durante el examen y la evaluación de las ofertas, así como las medidas adoptadas al respecto.

5. Si el Estado promulgante considera que la normativa y las directrices internas aplicables también deben archivar-se junto con el expediente y la documentación correspondiente a determinado contrato, el reglamento de la contratación pública o las normas pertinentes, o las directrices del organismo de contratación pública u otra autoridad pueden exigirlo.

Artículo 26. Código de conducta [\[hiperenlace**\]](#)**

1. Dependiendo de la tradición jurídica de los Estados promulgantes, puede promulgarse un código de conducta especialmente para el personal encargado de la contratación pública, dentro del marco jurídico administrativo del Estado, al mismo nivel o como parte del reglamento de la contratación pública.

2. Si el código de conducta se promulga al margen del reglamento de la contratación pública, y si procede, este último debe disponer la manera en que se pondrá sin demora a disposición del público y se actualizará sistemáticamente²².

IV. Temas que deberán tratarse en el reglamento de la contratación pública en el contexto de las cuestiones generales planteadas por las disposiciones del Capítulo II de la Ley Modelo (Métodos de contratación y sus condiciones de empleo; convocatoria y anuncios de la contratación) [\[hiperenlace**\]](#)**

1. El reglamento de la contratación pública debe determinar la publicación en que habrá de anunciarse la convocatoria a licitación o a presentar otras ofertas, o en que aparecerá el preaviso del contrato adjudicable. También determinará el medio y la forma de publicación de las convocatorias y los avisos. Estos se podrán publicar

²² En este contexto, véase el comentario de la Guía sobre el artículo 5.1 de la Ley Modelo, en el que se prevé un requisito análogo para los textos jurídicos de aplicación general.

por medios electrónicos o en papel, o de las dos maneras, como se explica en el comentario de la Guía sobre el artículo 5.

2. El reglamento debe contener normas para la publicación internacional de la convocatoria a licitación o a presentar otras propuestas, es decir, en los medios de información de circulación internacional y en la forma y el idioma que garanticen que la convocatoria llegue debidamente a conocimiento de los círculos internacionales de proveedores y contratistas.

3. También puede exigir que las entidades adjudicadoras publiquen la convocatoria a licitación o a presentar otras propuestas por otros medios que permitan dar amplia publicidad al proceso de contratación entre los proveedores y contratistas. Esos medios podrían comprender, por ejemplo, el anuncio de la convocatoria en tableros de anuncios oficiales o en un boletín de contratos y su distribución a cámaras de comercio, a misiones comerciales extranjeras en el país de la entidad adjudicadora y a misiones comerciales del propio país en el extranjero. Cuando la entidad adjudicadora utilice medios electrónicos de publicidad y comunicación, el reglamento puede permitir que en la convocatoria se incluya un enlace que incluso permita ver el texto del pliego de condiciones.

4. El reglamento debe regular detalladamente las excepciones a la regla general sobre la publicación internacional de la convocatoria, ya sea por tratarse de una contratación nacional o porque la entidad adjudicadora considere improbable, debido al poca cuantía de la contratación prevista, que esta despierte mucho interés de parte de los proveedores o contratistas extranjeros. Las cuestiones relacionadas con la contratación de poca cuantía se examinaron en la sección II.C del presente documento. Como allí se ha indicado, el reglamento debe determinar sistemáticamente lo que constituye una contratación de poca cuantía a efectos de aplicar las exoneraciones pertinentes de la Ley Modelo. Al respecto, cabe explicar que en los dos casos en que se aplica la exoneración de la publicación internacional la entidad adjudicadora aún puede comunicar la convocatoria internacionalmente; si no lo hace, pero hay proveedores o contratistas que desean participar (por ejemplo, si han visto un anuncio en la Internet), deben estar autorizados a hacerlo.

5. Como se observó anteriormente en el contexto del artículo 8, el reglamento de la contratación pública debe precisar las razones para utilizar la contratación nacional; si esas razones están previstas en otras normas jurídicas del Estado promulgante, el reglamento debe remitirse a ellas.

V. Temas que deberán tratarse en el reglamento de la contratación pública en especial en el contexto de los artículos del Capítulo III de la Ley Modelo (Licitación abierta) [\[hiperenlace**\]](#), expuestos en el orden de los artículos correspondientes**

Artículo 38. Entrega del pliego de condiciones [\[hiperenlace**\]](#)**

Las consideraciones relativas a la comisión que puede cobrarse por facilitar el pliego de condiciones se examinaron en la sección II.D del presente documento y son pertinentes en el contexto de este artículo.

Artículo 39. Contenido del pliego de condiciones [\[hiperenlace**\]](#)**

1. Si el pliego de condiciones debe contener determinada información mínima además de la enumerada en la ley, el reglamento de la contratación pública debe precisarla o remitirse a otras normas jurídicas del Estado promulgante en las que pueda estar enumerada.
2. En el contexto del apartado g) del artículo, en la medida en que el fomento de las pequeñas y medianas empresas forme parte de la política socioeconómica del gobierno interesado, se puede alentar a la entidad adjudicadora a que considere la posibilidad de admitir ofertas parciales en el pliego de condiciones.

Artículo 40. Presentación de ofertas [\[hiperenlace**\]](#)**

1. El reglamento debería impartir orientación o exigir que se impartieran directrices con respecto a diversos aspectos de la presentación de ofertas en el contexto de las comunicaciones que no se consignen sobre papel. Como mínimo, debería exigir que el sistema de la entidad adjudicadora garantizara que ninguna persona tuviese acceso al contenido de las ofertas tras haber sido recibidas por la entidad adjudicadora y antes del momento fijado para la apertura oficial de las ofertas. También ha de garantizar que únicamente las personas autorizadas cuya identidad conste claramente en el sistema tengan derecho a abrir las ofertas en el momento de su apertura oficial y tengan acceso a su contenido en las etapas posteriores del proceso de adjudicación. Además, el sistema se ha de configurar de modo que permita seguir de cerca todas las operaciones relativas a las ofertas presentadas, entre otras cosas, saber la hora y la fecha exactas en que se recibieron, quién fue la persona que tuvo acceso a las ofertas y en qué momento y si las ofertas a las que supuestamente estaba vedado el acceso han quedado en entredicho o se han manipulado. Deberían preverse medidas apropiadas para comprobar que las ofertas no se borran o se vieran menoscabadas, ni resultaran afectadas de otra forma no autorizada cuando se abrieran y posteriormente se utilizaran. Se puede lograr un alto grado de autenticación y de seguridad utilizando diversos programas informáticos comerciales disponibles en todo momento, pero eso no procedería en los procesos de contratación pública de poca cuantía y poco riesgo. La elección debería basarse, pues, en un análisis de costos y beneficios²³.
2. En las situaciones en que el sistema de recepción de las ofertas no permita establecer con precisión el momento en que se han recibido las ofertas presentadas, tal vez deba darse a la entidad adjudicadora cierto margen de discrecionalidad para determinar el grado de precisión con que ese momento quedaría registrado. Ahora bien, a fin de prevenir abusos y garantizar objetividad, el reglamento debería regular ese margen discrecional remitiéndose a las normas jurídicas aplicables en el comercio electrónico.
3. Es inevitable que en los sistemas automáticos se produzcan fallos que impidan a los proveedores o contratistas presentar sus ofertas antes de que venza el plazo. El reglamento debe prever esas situaciones y dar opciones para que la entidad adjudicadora las solucione. Por ejemplo, como se indica en el comentario de la Guía sobre el artículo 40, cuando se produzca un fallo, la entidad adjudicadora ha de determinar si es posible restablecer el funcionamiento del sistema con la celeridad

²³ Véase el párr. 3 del comentario de la Guía sobre el artículo 40.

necesaria para que prosiga el proceso de adjudicación y, en tal caso, decidir si será o no necesario prorrogar el plazo para la presentación de ofertas. No obstante, si la entidad adjudicadora determina que un fallo en el sistema le impide seguir adelante con el proceso, podrá cancelarlo y convocar otro. Toda deficiencia funcional de los sistemas automáticos que sea imputable a algún acto imprudente o intencional de la entidad adjudicadora, así como las decisiones adoptadas por esta para responder a los problemas derivados de las deficiencias de esos sistemas, pueden dar lugar a una impugnación por parte de los proveedores y contratistas perjudicados, en virtud del Capítulo VIII de la Ley Modelo²⁴.

Artículo 42. Apertura de las ofertas [\[hiper enlace**\]](#)**

1. El reglamento debe regular detalladamente los medios y la manera de contar con la presencia de los proveedores o contratistas en el acto de apertura de las ofertas, ya sea en persona o en forma virtual. Debe exigir a la entidad adjudicadora que, si decide utilizar comunicaciones no consignadas sobre papel, exclusivamente o en combinación con documentos en papel, establezca modalidades para la apertura de las ofertas (lugar, modo, hora y procedimientos de apertura) que permitan la presencia física y virtual de los proveedores o contratistas. Pueden enumerarse los factores que se han de tener en cuenta en esas situaciones, entre ellos la diferencia horaria y la necesidad de complementar toda ubicación física designada para la apertura de las ofertas con cualquier medio que garantice la asistencia de los que no puedan personarse en ese lugar u opten por una ubicación virtual²⁵.
2. Como se observó anteriormente en el contexto del artículo 7, deben explicarse los conceptos de “habitualmente empleados” y “participar plena y simultáneamente en las reuniones”. En relación con este último, puede recurrirse a la explicación que figura en el párrafo 3 del comentario de la Guía sobre el artículo 42: la expresión “plena y simultáneamente” significa que se debe dar a los proveedores o contratistas la oportunidad de recibir al mismo tiempo toda y exactamente la misma información comunicada durante la apertura. La información en cuestión comprende los anuncios hechos de conformidad con el párrafo 3 del artículo. Los proveedores o contratistas también deben tener la posibilidad de intervenir cuando se observe alguna irregularidad o incorrección, en la medida en que estarían autorizados para hacerlo si estuvieran físicamente presentes. Independientemente del método utilizado, toda la información pertinente debe comunicarse a los proveedores o contratistas con suficiente anticipación como para permitirles participar en la apertura de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4.
3. El reglamento también debe establecer salvaguardias especiales en relación con la apertura automática de las ofertas, por ejemplo: a) que únicamente las personas autorizadas cuya identidad conste claramente en el sistema tengan derecho a fijar o cambiar en este el momento de la apertura de las ofertas de conformidad con el párrafo 1 del artículo, sin comprometer la seguridad, integridad ni confidencialidad de estas; b) que solo esas personas estén facultadas para abrir las ofertas en el momento establecido. Se puede exigir que por lo menos dos personas autorizadas lleven a cabo simultáneamente la apertura de las ofertas. En este

²⁴ Párr. 6 del comentario de la Guía sobre el artículo 40.

²⁵ Véase el comentario de la Guía sobre el artículo 7.4, donde figura un examen más a fondo de los requisitos pertinentes.

contexto, se entiende por “simultáneamente” que las personas autorizadas designadas abran, dentro de casi el mismo lapso, los mismos componentes de una oferta y tomen nota de los componentes que se hayan abierto y del momento en que se abrieron; c) que, antes de la apertura de las ofertas, el sistema confirme las condiciones de seguridad de estas comprobando que nadie se haya enterado de su contenido sin autorización; d) que se dote a las personas autorizadas de medios idóneos para comprobar la autenticidad e integridad de las ofertas y su presentación oportuna sin que puedan modificarlas de ninguna manera; e) que se adopten medidas para impedir que quede en entredicho la integridad de las ofertas, que estas se borren o que se destruya el sistema cuando proceda a abrir las ofertas, por ejemplo, a causa de un virus o de una perturbación parecida; f) que el sistema se configure de modo que permita seguir de cerca todas las operaciones realizadas durante la apertura, entre ellas, comprobar la identidad de la persona que abrió cada una de las ofertas y sus componentes, así como la fecha y hora en que lo hizo, y g) que el sistema también garantice que solo puedan seguir teniendo acceso a las ofertas abiertas las personas autorizadas a tomar conocimiento de su contenido y de los datos pertinentes (por ejemplo, los miembros de un comité de evaluación o los auditores en etapas posteriores del proceso de adjudicación)²⁶.

Artículo 43. Examen y evaluación de las ofertas [\[hiperenlace**\]](#)**

1. En el reglamento se debería explicar lo que se entiende por que la oferta se aparte ligeramente de las características, cláusulas, condiciones y demás requisitos enunciados en el pliego de condiciones y que adolezca de errores u omisiones, en comparación con los errores aritméticos cuya rectificación está prevista en el artículo 16 de la Ley Modelo [\[**hiperenlace**\]](#). Se debe hacer hincapié en que debería aceptarse toda diferencia, error u omisión que se pudiera corregir sin alterar el fondo de la oferta, es decir, que no significara ningún cambio sustantivo ni se apartara considerablemente de las características, cláusulas, condiciones y demás requisitos enunciados en el pliego de condiciones. No obstante, la rectificación de un error u omisión en ningún caso podrá redundar en una modificación sustantiva de la oferta, es decir, una modificación por la que un proveedor o contratista no calificado pase a estar calificado o por la que una oferta no conforme pase a ser conforme. Deberían darse ejemplos prácticos de diferencias, errores y omisiones aceptables e inaceptables.
2. El reglamento debería contener normas para la cuantificación de las diferencias menores, errores y omisiones y para tenerlos en cuenta debidamente en el examen y la evaluación de las ofertas, de manera que se pudiera comparar a los concursantes de manera objetiva y equitativa.
3. Se deben prever garantías procesales para mitigar el riesgo de que se utilicen prácticas discriminatorias al aplicar las disposiciones relativas a la rectificación y cuantificación de las diferencias menores, errores y omisiones, por ejemplo, exigiendo a la entidad adjudicadora que deje constancia de toda diferencia menor, error y omisión que se haya constatado durante el proceso de examen y evaluación, así como las medidas adoptadas al respecto.
4. Para regular exhaustivamente todas las cuestiones relacionadas con los errores u omisiones que figuren en las ofertas y la posible aclaración y rectificación de

²⁶ Párrs. 6 y 7 del comentario de la Guía sobre el artículo 42.

estos, ya sea por parte de la entidad adjudicadora o del proveedor o contratista, tal vez haya que remitirse al derecho de los contratos y a otras ramas del derecho del Estado promulgante, así como reflejar las disposiciones de un acuerdo internacional en el que este sea parte, por ejemplo, el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC.

5. En relación con los párrafos 5 y 6 del artículo, se debe orientar a la entidad adjudicadora con respecto a las opciones de que dispone con arreglo al artículo si el concursante ganador no puede volver a demostrar su idoneidad: cancelar el procedimiento de contratación o adjudicar el contrato al concursante que ocupe el segundo lugar. Se debería exigir a la entidad adjudicadora que determinara las consecuencias de la cancelación del procedimiento, en particular los costos que entrañaría la aplicación de otro método de contratación. No debería alentarse siempre a la entidad adjudicadora a optar por el concursante que ocupara el segundo lugar. Puede ser necesario cancelar el procedimiento, por ejemplo, cuando se sospeche que ha habido colusión entre el proveedor o contratista que presentó la oferta ganadora y el que ocupa el segundo lugar, ya que eso puede desembocar en la aceptación de una oferta con un precio anormalmente elevado. Se debe exigir a la entidad adjudicadora que haga constar en el expediente los detalles de los procedimientos previstos en los párrafos 5 y 6 del artículo si efectivamente se han aplicado, así como las decisiones que haya adoptado al respecto y las razones para hacerlo.

VI. Temas que deberán tratarse en el reglamento de la contratación pública en el contexto de los métodos de contratación mencionados en el Capítulo IV de la Ley Modelo (Procedimientos de licitación restringida, solicitud de cotizaciones y solicitud de propuestas sin negociación) [\[hiperenlace**\]](#)**

La licitación restringida y la convocatoria directa para la solicitud de propuestas

1. En el contexto de la aplicación del procedimiento de licitación restringida o de la solicitud de propuestas para la adquisición de productos que solo pueden obtenerse de un número limitado de proveedores o contratistas, el reglamento de la contratación pública debe regular la cuestión de la definición del mercado y la salvaguardia de que la entidad adjudicadora invite a participar a todos los posibles proveedores o contratistas que puedan entregar los productos adquiridos. En este contexto, se debería regular el requisito del preaviso de la contratación y sus consecuencias para esta, en particular que, si al anuncio de la contratación responden proveedores que no se conocían anteriormente, se les debe permitir presentar una oferta o una propuesta, a no ser que estén descalificados o que por alguna otra razón no cumplan las condiciones que figuren en el anuncio. El reglamento debe exigir una licitación abierta, con una convocatoria o precalificación pública e irrestricta, cuando no se conozca o no se entienda bien la amplitud del mercado, en particular en lo que respecta al grupo de proveedores o contratistas

extranjeros y al grado de interés de estos en el proceso de contratación del Estado promulgante.

2. Se deben disponer medidas para mitigar el riesgo de recargar la labor administrativa y retrasar el proceso si surgiera otro proveedor o contratista, a la luz de los artículos 14 y 15 [\[**hiperenlaces**\]](#), que disponen que se dé tiempo suficiente a los concursantes para presentar sus ofertas. El reglamento puede exigir que en el preaviso se pida a los proveedores o contratistas interesados que se identifiquen ante la entidad adjudicadora antes de la fecha en que se publique el pliego de condiciones y se entregue a los proveedores o contratistas conocidos.

3. En lo que respecta al empleo de la convocatoria directa para evitar los gastos desproporcionados que entrañaría el examen de un gran número de ofertas o propuestas en relación con el valor del objeto del contrato adjudicable, el reglamento debe establecer un número mínimo razonable de proveedores o contratistas, por ejemplo, cinco, para garantizar una competitividad efectiva, y una manera objetiva de seleccionar a los proveedores o contratistas que se invite a participar, por ejemplo, por orden de presentación de las ofertas, por sorteo, por rotación o al azar en un mercado de productos básicos.

La solicitud de cotizaciones

1. En el reglamento de la contratación pública deben precisarse las condiciones y normas relativas a la aplicación de este método de contratación teniendo en cuenta que es fundamental garantizar la suficiente transparencia, dado que en ese caso la contratación no tiene que ir precedida de un anuncio y puede no llegar al umbral fijado para que se anuncie públicamente el contrato adjudicado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 [\[**hiperenlace**\]](#). El reglamento debe precisar la clase de productos que podrán adquirirse mediante ese método de contratación. Se podría exigir que se emplearan cláusulas comerciales reconocidas, en particular las Incoterms u otras descripciones comerciales uniformes utilizadas comúnmente -como las que se usan en los mercados de tecnología de la información y las comunicaciones- a fin de que los productos corrientes para los que está pensado ese método pudieran definirse utilizando como referencia las normas del sector industrial correspondiente.

2. El reglamento debería exigir a la entidad adjudicadora que siempre considerara la posibilidad de utilizar otras opciones en lugar de la solicitud de cotizaciones, especialmente en los casos en que las adquisiciones se efectuaran normalmente por vía electrónica. Los métodos electrónicos para solicitar cotizaciones en general resultan particularmente económicos si el objeto del contrato adjudicable es de poca cuantía, y también garantizan una selección más transparente.

3. Cuando no se disponga de otras opciones, el reglamento debe prever la manera de conseguir participantes, a efectos de garantizar que la selección de los participantes en esos casos no se lleve a cabo de una forma que limite el acceso al mercado o que dé lugar a abusos del procedimiento. Como ejemplos de abuso cabría citar la selección de dos proveedores o contratistas a sabiendas de que sus precios son muy elevados, o que se encuentren en lugares remotos, de modo de orientar la contratación hacia un tercer proveedor o contratista preferido, o de proveedores o contratistas integrantes de un grupo de sociedades o que estén sometidos a alguna otra forma de control financiero y administrativo común. Puede exigirse la

comparación con ofertas anteriores y la rotación de los proveedores o contratistas, si ocasionalmente se contratan los mismos bienes o servicios. Para aumentar la transparencia en la selección de los proveedores o contratistas a los que se pedirán cotizaciones, puede considerarse, en particular, la posibilidad de emplear catálogos electrónicos para averiguar las cotizaciones, ya que de ese modo se pueden comparar las cotizaciones de los proveedores o contratistas escogidos con los precios de productos pertinentes que se ofrecen en los catálogos. Si bien no está previsto en la Ley Modelo, también se puede exigir que se publique un preaviso de la contratación, como en otros casos de convocatoria directa. Se pueden disponer procedimientos especiales de supervisión para determinar cuáles son los proveedores o contratistas que han obtenido adjudicaciones mediante ese método con el fin de que puedan evaluarse las adjudicaciones reiteradas.

La solicitud de propuestas sin negociación

1. Además de las cuestiones destacadas anteriormente en relación con la licitación restringida y la convocatoria directa para la solicitud de propuestas, en el reglamento de la contratación pública debería explicarse el propósito de este método de contratación y deberían mencionarse ejemplos para ilustrar las situaciones en que podría aplicarse de manera provechosa. También debería distinguirse claramente el alcance de las “características técnicas, de calidad y de rendimiento” de las propuestas de sus “aspectos financieros”. En el comentario que figura en la Guía acerca de la solicitud de propuestas sin negociación se ofrecen ejemplos prácticos de los elementos de las propuestas que podrían estar comprendidos en una u otra categoría²⁷.
2. El reglamento debe precisar la información mínima no enumerada en la ley que debe incluir la entidad adjudicadora en el pliego de condiciones. Si esa información está especificada en otras normas jurídicas del Estado promulgante, el reglamento debe remitirse a ellas.
3. En la sección II.D del presente documento se examinan las consideraciones relativas al precio del pliego de condiciones, que son pertinentes en el contexto de los apartados h) e i) del artículo 47.2. Por consiguiente, el reglamento debería abordarlas también en el contexto de este método de contratación.
4. Si lo permite el régimen de la contratación pública del Estado promulgante, se puede prever una variación de este método de contratación que puede ser apropiada para la adjudicación de un contrato cuyo objeto sea más sencillo: la entidad adjudicadora podrá determinar la propuesta ganadora en función del precio de las propuestas que reúnan, por lo menos, los requisitos técnicos, de calidad y de rendimiento mínimos, siempre y cuando en la exposición de los criterios de evaluación que se haya hecho en la convocatoria y la solicitud de propuestas así se haya previsto. Ese enfoque puede ser apropiado en situaciones en que la entidad adjudicadora no necesite evaluar los aspectos técnicos, de calidad y de rendimiento de las propuestas ni puntuarlas, sino en que establezca un límite de referencia tan alto para medir esos aspectos que todos los proveedores o contratistas que obtengan una puntuación equivalente o superior al nivel establecido con toda probabilidad

²⁷ Párr. 2 del comentario de la Guía sobre la descripción general y las principales cuestiones de política de la solicitud de propuestas sin negociación.

podrán ejecutar el contrato adjudicable con un grado de competencia más o menos equivalente. Además, en esos casos no debería ser necesario evaluar los aspectos financieros de las propuestas que no fueran el precio.

VII. Temas que deberán tratarse en el reglamento de la contratación pública en el contexto de los métodos de contratación mencionados en el Capítulo V de la Ley Modelo (Métodos de contratación por licitación en dos etapas, solicitud de propuestas con diálogo, solicitud de propuestas con negociación consecutiva, negociación competitiva y contratación con un único proveedor o contratista) **[hiperenlace**]****

Observaciones generales

1. El reglamento puede ayudar a evaluar con más objetividad las circunstancias en las cuales es necesario emplear uno de los métodos de contratación previstos en el Capítulo V. Como la evaluación se realizará en la etapa de planificación de la contratación, el reglamento debería establecer salvaguardias adecuadas en esa etapa, entre ellas el requisito de que quede plenamente documentada y se deje constancia de todas las actuaciones correspondientes.
2. Se debería prever la asistencia de expertos externos a la entidad adjudicadora -asistencia que podrá prestarse de manera centralizada o provenir de otras fuentes- a fin de que pudiera desarrollar su capacidad para entablar conversaciones, diálogos o negociaciones fructíferas con el sector privado y explicar sus necesidades de manera que todos los participantes las entendieran completamente y por igual, así como evaluar las ofertas y propuestas resultantes de manera que se atendiera plenamente a sus necesidades.
3. También deberían preverse instrumentos de gestión, estructuras y salvaguardias procesales para el empleo de métodos de contratación que entrañasen interacción con el mercado, en particular los encaminados a evitar la posibilidad de que se cometieran abusos y actos de corrupción. Concretamente, cuando se trate de una contratación en la que se planteen cuestiones delicadas, o de un contrato muy competitivo, el reglamento debería prever medidas de supervisión, entre ellas auditorías posteriores al procedimiento y la presencia de observadores ajenos a la estructura de la entidad adjudicadora durante los procesos para evaluar la aplicación de los métodos en la práctica. Esas medidas deberían tener por objeto prevenir la posibilidad de que se favoreciera a determinados proveedores o contratistas, por ejemplo, proporcionando información diferente a cada uno de ellos durante las conversaciones, el diálogo o las negociaciones, y mitigar el riesgo de revelar, inadvertidamente o no, información comercial de carácter delicado sobre los proveedores o contratistas concursantes.

La licitación en dos etapas

1. El reglamento de la contratación pública debería ayudar a la entidad adjudicadora a determinar las circunstancias en las cuales es necesario emplear este método de contratación. Puede ofrecer ejemplos de casos en los que ha dado buenos resultados, entre ellos, contratos relativos a productos de alta tecnología como grandes aeronaves de pasajeros o sistemas de comunicaciones, equipo técnico e infraestructura, por ejemplo, grandes instalaciones complejas o construcciones de carácter especializado. En un sentido más general, pueden darse instrucciones a la entidad adjudicadora para que considere la posibilidad de aplicar ese método en la etapa de planificación de la contratación cuando sea evidente que será muy poco probable que se pueda obtener una buena relación costo-calidad, si esta formula una descripción completa del contrato adjudicable, enunciando todas las especificaciones técnicas, todas las características de calidad y rendimiento del objeto del contrato, todos los requisitos de idoneidad pertinentes de los proveedores o contratistas y todas las condiciones contractuales, sin examinar lo que el mercado puede ofrecer.
2. Se debería impartir orientación a la entidad adjudicadora acerca de todas las excepciones que cabría hacer para aplicar a la licitación en dos etapas las disposiciones generales relativas a la licitación abierta que figuran en el Capítulo III de la Ley Modelo. Esas excepciones se ejemplifican en los párrafos 1 a 3 del comentario que figura en la Guía sobre los procesos de licitación en dos etapas.
3. El reglamento de la contratación pública puede desarrollar las disposiciones de la Ley Modelo en lo que respecta a la presentación, el examen y el rechazo de las ofertas iniciales. En particular, se pueden enumerar razones para rechazar las ofertas iniciales, recurriendo a la lista que figura en el artículo 43.2 de la Ley Modelo [\[**hiperenlace**\]](#), según proceda (y observar que las razones relacionadas con los precios de las ofertas no serían aplicables, ya que en las ofertas iniciales no se incluye el precio).
4. Debería explicarse el propósito y el carácter de las conversaciones sostenidas en ese método de contratación, en particular, que esas conversaciones no entrañan negociaciones vinculantes ni negociación del precio de ninguna índole y pueden relacionarse con cualquiera de los aspectos de las ofertas iniciales que no fueron rechazadas, excepto con el precio. Cabe hacer hincapié en que entablar esas conversaciones es una opción, no una obligación: la entidad adjudicadora tal vez pueda perfeccionar y ultimar las condiciones contractuales sin necesidad de entablar conversaciones, únicamente sobre la base de las ofertas iniciales recibidas.
5. Debería explicarse la noción de ofrecer por igual a todos los proveedores o contratistas oportunidad de sostener conversaciones. En ese contexto, la frase “ofrecerá por igual la oportunidad” significa que los proveedores o contratistas serán tratados en pie de igualdad, sin perjuicio del requisito de no revelar información confidencial y de la necesidad de evitar la colusión. El reglamento debe establecer medidas para vigilar que la entidad adjudicadora cumpla ese requisito imperativo, por ejemplo, exigir que se deje constancia de los pormenores de las conversaciones sostenidas con cada uno de los proveedores o contratistas en el expediente del proceso de adjudicación.

6. Debe alertarse de que el riesgo de revelar, inadvertidamente o no, información comercial de carácter delicado acerca de los proveedores o contratistas concursantes puede existir no solo en la etapa de las conversaciones, sino también en la de la revisión del conjunto de condiciones contractuales. Según lo dispuesto en el artículo 24 [\[**hiperenlace**\]](#), la entidad adjudicadora debe respetar la confidencialidad de las propuestas técnicas de los proveedores o contratistas a lo largo de todo el proceso. El reglamento debe impartir orientación práctica al respecto, por ejemplo, en el sentido de prohibir a la entidad adjudicadora que revele la fuente de información utilizada para formular la revisión de las características técnicas, de calidad y de rendimiento del objeto del contrato y exigirle que en la revisión de las condiciones contractuales evite emplear símbolos y terminología peculiares de un solo proveedor o contratista.

La solicitud de propuestas con diálogo

1. El reglamento de la contratación pública debería ayudar a la entidad adjudicadora a determinar las circunstancias en las cuales es necesario emplear este método de contratación. Puede ofrecer ejemplos de casos en los que haya dado buenos resultados, por ejemplo, en los procesos de contratación encaminados a obtener diferentes soluciones técnicas, a menudo innovadoras. También puede ser apropiado para la contratación de obras de arquitectura, de construcción y de infraestructura en las que se procure economizar energía y alcanzar otros objetivos de contratación sostenible. En esos casos podría haber numerosas soluciones para atender a las necesidades de la entidad adjudicadora: el material puede variar y también puede utilizarse una fuente de energía en lugar de otra (por ejemplo, eólica o solar, en lugar de combustibles fósiles). La complejidad puede no ser de índole técnica; así, por ejemplo, en proyectos de infraestructura las principales variables podrían radicar en los diversos lugares y tipos de obras. En proyectos menos complejos puede necesitarse una solución a la medida de las necesidades, por ejemplo, cuando se trate de un sistema de comunicaciones para el archivo de expedientes que deba reunir determinadas características, por ejemplo, accesibilidad a largo plazo, y en que la excelencia técnica sea un factor primordial. En todos esos casos, la idoneidad de las soluciones y la competencia y pericia del proveedor o contratista únicamente pueden determinarse por medio del diálogo; este es esencial para determinar y obtener la solución que mejor atienda a las necesidades de la contratación. Así pues, el costo de oportunidad que entraña el hecho de no entablar un diálogo con los proveedores o contratistas es elevado, en tanto que las ventajas económicas que reporta emprender ese proceso son evidentes.

2. Debe aclararse en qué casos no ha de aplicarse ese método. Como el diálogo suele ser un proceso complejo y prolongado, no debería emplearse cuando se tratara de productos sencillos y fáciles de obtener mediante métodos de contratación que no exigiesen interacción alguna con los concursantes. Por ejemplo, no procedería recurrir a él en los casos en que hubiera que entablar negociaciones por razones de urgencia, o en que existiera una base competitiva insuficiente (en esos casos la Ley Modelo prevé la posibilidad de recurrir a la negociación competitiva o a la contratación con un solo proveedor). No sirve para el tipo de negociaciones encaminadas únicamente a obtener rebajas de precios, como en la solicitud de propuestas con negociación consecutiva. Tampoco debe aplicarse en situaciones en

que la entidad adjudicadora desee definir mejor sus necesidades y tenga previsto formular un único conjunto de condiciones contractuales (incluidas las especificaciones técnicas) al que deberá atenerse toda oferta que desee presentarse, casos estos en los que debería emplearse el método de licitación en dos etapas.

3. Habida cuenta de las numerosas similitudes que existen en las condiciones de empleo y las características del método de licitación en dos etapas y el de solicitud de propuestas con diálogo, debe aclararse bien el propósito de aplicar el segundo en lugar del primero. Una de las principales características singulares de la solicitud de propuestas con diálogo es que no existe un único conjunto completo de condiciones del contrato adjudicable, aparte de los requisitos mínimos, para evaluar las ofertas definitivas. La entidad adjudicadora recurrirá a ese método si llega a la conclusión de que no es posible o no sería adecuado formular un único conjunto completo de condiciones del contrato adjudicable y, por consiguiente, de que la contratación no tendrá éxito si no se procede a dialogar con los proveedores o contratistas.

4. Si bien el procedimiento no obliga a la entidad adjudicadora a formular una descripción técnica completa del objeto del contrato adjudicable, el método no debe utilizarse como medida sustitutiva de la debida preparación de la contratación. En consecuencia, en el reglamento deben enumerarse las cuestiones que se han de examinar en la etapa de planificación de la contratación para poder aplicar el método con éxito, por ejemplo, determinar los requisitos técnicos mínimos y demás necesidades del proyecto y los parámetros que no puedan modificarse durante el diálogo.

5. Debería explicarse el propósito y el carácter de ese diálogo, en particular, que puede abarcar cualquiera de los aspectos de las propuestas, incluso el precio. Si bien el diálogo se suele centrar principalmente en los aspectos técnicos, de calidad y de rendimiento, o en cuestiones jurídicas o cuestiones auxiliares de la contratación, puede suceder que el objeto del contrato adjudicable y las condiciones del mercado hagan posible, e incluso conveniente, que la entidad adjudicadora utilice el precio como aspecto del diálogo. Además, en algunos casos no es posible disociar el criterio del precio de los demás criterios.

6. También cabe explicar que el diálogo no entraña negociaciones vinculantes ni negociación alguna del precio. Deberían enumerarse los requisitos necesarios para sostener un diálogo concomitante, entre otras cosas, que todos los proveedores o contratistas seleccionados por la entidad adjudicadora de conformidad con las condiciones de la convocatoria tengan derecho a participar por igual, sin que se prevean conversaciones consecutivas, y que el diálogo se lleve a cabo en diferentes momentos con los distintos proveedores o contratistas y esté a cargo de los mismos funcionarios que gestionen la contratación pública o los mismos comités de negociación compuestos por los mismos funcionarios competentes.

7. Si se promulgan las disposiciones por las que se exige un mecanismo de aprobación previa de la aplicación de ese método de contratación²⁸, se deben regular las prerrogativas que tendrá en el proceso de contratación la autoridad prevista en el ordenamiento jurídico del Estado promulgante que se encargará de aprobarlo, indicando, en particular, si esas prerrogativas quedarán sin efecto una vez

²⁸ Al respecto, véase el párr. 5 del comentario de la Guía sobre las condiciones para emplear la solicitud de propuestas con diálogo (artículo 30.2).

que autorice a la entidad adjudicadora a recurrir al método, o si seguirá ejerciendo alguna clase de supervisión del modo en que se lleva a cabo el procedimiento. Al respecto, debe prestarse atención especial a la necesidad de evitar los conflictos de intereses en esa etapa y en etapas posteriores del proceso de contratación, si, por ejemplo, la misma entidad aprueba el empleo del método y posteriormente la entrada en vigor del contrato, o si entiende de las demandas que se entablen más adelante.

8. Las consideraciones planteadas en relación con los métodos de convocatoria a licitación en la sección IV del presente documento y con determinados aspectos de la convocatoria directa en la sección VI, en el contexto de la licitación restringida y la solicitud de propuestas, son pertinentes para el procedimiento de solicitud de propuestas con diálogo. En consecuencia, esos aspectos también deberían abordarse en el contexto de ese método de contratación pública.

9. Se debería recomendar que se llamara a dialogar a tres proveedores o contratistas como mínimo y, si se establece un número máximo de proveedores o contratistas a los que se invitará a presentar propuestas, ese número debería ser mayor que el de los admitidos a la etapa de diálogo, a fin de que hubiese un grupo más grande para que la entidad adjudicadora pudiera elegir los candidatos más idóneos para participar en esta.

10. Al mismo tiempo, deberían abordarse las situaciones en que únicamente se presentaran una o dos propuestas conformes. No se debería impedir que la entidad adjudicadora prosiguiera la contratación en esos casos, ya que esta no dispone de medios para garantizar que la base competitiva se conserve hasta el final de la etapa de diálogo, dado que nada impide que en cualquier momento un concursante se retire del proceso.

11. El reglamento de la contratación pública debería enumerar todos los motivos por los cuales, con arreglo al derecho interno del Estado promulgante, la entidad adjudicadora podría excluir del diálogo a determinados participantes, habida cuenta de que la Ley Modelo no le confiere un derecho incondicional a dar por terminado el diálogo competitivo con ningún concursante por la única razón, por ejemplo, de que, en su opinión, no tenga posibilidades reales de que se le adjudique el contrato. Por otra parte, los concursantes deben ser excluidos sobre la base del artículo 21 [\[**hiperenlace**\]](#) (por haber ofrecido algún incentivo o por gozar de alguna ventaja competitiva desleal o adolecer de algún conflicto de intereses), o si dejan de ser idóneos (por ejemplo, en caso de quiebra), o si durante la etapa de diálogo sus ofertas dejan de cumplir requisitos esenciales de la contratación (es decir, por ejemplo, con respecto al objeto del contrato adjudicable, los requisitos mínimos de idoneidad o los aspectos que no son materia de diálogo, establecidos al comienzo del proceso de contratación).

12. En todos esos casos el reglamento puede exigir que la entidad adjudicadora notifique con prontitud a los concursantes su decisión de dar por terminado el diálogo y exponga los motivos de su decisión. Podría ser conveniente que les informara desde el principio del proceso de contratación de los motivos por los que pudiera verse obligada por la ley a excluirlos de este.

13. Debe promoverse una debida planificación de la contratación para que el proceso sea más predecible, en particular pidiendo a la entidad adjudicadora que indique en la solicitud de propuestas el calendario estimado que se ha previsto para

la contratación a fin de dar a las dos partes una mejor idea del momento en que tendrán lugar las diversas etapas, así como de los recursos pertinentes (entre otras cosas, personal, expertos, documentación y diseños) que deben proporcionarse en cada una de las etapas. También puede pedirse a la entidad adjudicadora que precise el plazo máximo durante el cual los concursantes habrán de dedicar tiempo y recursos al proceso.

14. Deberían establecerse límites con respecto a la posibilidad de modificar las condiciones iniciales del contrato adjudicable durante el diálogo, teniendo en cuenta que la flexibilidad para introducir cambios es inherente a ese método de contratación y que imponer restricciones excesivas a la entidad adjudicadora obrará en detrimento del propósito del procedimiento. La necesidad de hacer modificaciones puede verse justificada no solo de resultados del diálogo, sino también de circunstancias ajenas a este (como, por ejemplo, ciertas medidas administrativas).

15. Se deben proporcionar ejemplos prácticos acerca de las modificaciones que serían aceptables o no a la luz de los requisitos establecidos en el artículo 49.9. En general, estaría permitida toda modificación, a menos que se intentara introducir modificaciones en las condiciones esenciales de la contratación de tal envergadura que dieran lugar a tener que anunciar un nuevo concurso (el objeto del contrato adjudicable, los criterios de calificación y evaluación, los requisitos mínimos o cualquier elemento que la entidad adjudicadora hubiese excluido expresamente del diálogo al comienzo del proceso de adjudicación).

16. Se deben enumerar medidas prácticas encaminadas a dar un trato justo, igualitario y equitativo a todos los participantes durante el diálogo. Además de los aspectos mencionados en la Ley Modelo (por ejemplo, que el diálogo se desarrolle de forma concomitante y esté a cargo de los mismos representantes de la entidad adjudicadora, así como los relativos a la circulación de los documentos pertinentes y la información que se proporcione a los concursantes), el reglamento debería prever otras medidas posibles, por ejemplo, con objeto de asegurarse de que se examinara la misma cuestión con los participantes de forma concomitante y durante el mismo tiempo, así como las normas para establecer la secuencia de las reuniones celebradas con los diferentes participantes.

17. Debe explicarse que la prohibición de negociar después de que se presenten las mejores ofertas definitivas excluye la posibilidad de pedir aclaraciones con arreglo al artículo 16 [\[**hiperenlace**\]](#), sin perjuicio de las limitaciones impuestas por ese artículo, como la prohibición de cambiar el precio u otra información importante durante el proceso de solicitud de aclaraciones.

18. El reglamento debe exigir a la entidad adjudicadora que deje constancia por escrito de los detalles del diálogo sostenido con cada uno de los participantes y que conserve esa información.

La solicitud de propuestas con negociación consecutiva

1. El reglamento de la contratación pública debería ayudar a la entidad adjudicadora a determinar las circunstancias en las cuales es necesario emplear este método de contratación. Puede ofrecer ejemplos de casos en los que haya dado buenos resultados, por ejemplo, en los que el objeto del contrato adjudicable era

más complejo y era posible y necesario examinar las características técnicas, de calidad y de rendimiento de las propuestas y sus aspectos financieros por separado, así como también era indispensable celebrar negociaciones sobre sus aspectos comerciales o financieros; puede haber tantas variables en esos aspectos de las propuestas que es imposible preverlos y precisarlos todos al principio del procedimiento, sino que hay que irlos perfeccionando y concertando durante las negociaciones. Cuando se han de negociar otros aspectos de las propuestas no puede recurrirse a ese método de contratación. En la práctica se ha utilizado para contratar servicios de consultores (por ejemplo, de asesoramiento).

2. Las consideraciones planteadas en relación con los métodos de convocatoria a licitación en la sección IV del presente documento y con determinados aspectos de la convocatoria directa en la sección VI, en el contexto de la licitación restringida y la solicitud de propuestas, son pertinentes para el procedimiento de solicitud de propuestas con negociación consecutiva. En consecuencia, esos aspectos también deberían abordarse en el contexto de este método de contratación pública.

3. Todas las etapas que preceden a la de negociación son las mismas que en la solicitud de propuestas sin negociación. En consecuencia, las cuestiones planteadas en ese contexto en la sección VI también deberían examinarse en relación con este método de contratación.

4. Deberían explicarse el propósito y el carácter de las negociaciones sostenidas, en particular, que pueden concernir únicamente a aspectos comerciales o financieros de las propuestas y que se celebran consecutivamente, no en forma concomitante, como, por ejemplo, en el curso de la negociación competitiva. Como en el caso de la solicitud de propuestas sin negociación, en el reglamento debería definirse claramente el alcance de las características “técnicas, de calidad y de rendimiento” de las propuestas y distinguirlas de sus “aspectos financieros”. En los comentarios de la Guía sobre la solicitud de propuestas sin y con negociación figuran ejemplos de los elementos de las propuestas que pueden estar comprendidos en una u otra categoría²⁹.

5. Debe hacerse hincapié en el requisito impuesto por la ley de que no puede adjudicarse un contrato a un proveedor o contratista con el que se hayan dado por terminadas las negociaciones. En el comentario pertinente de la Guía figuran las consideraciones que debería tener en cuenta la entidad adjudicadora al decidir dar por terminadas las negociaciones con el mejor concursante o con el que haya obtenido una mayor puntuación³⁰.

6. Es posible que haya que disponer medidas prácticas para mejorar la disciplina tanto de los proveedores o contratistas como de las entidades adjudicadoras a fin de que negocien de buena fe. También pueden establecerse medidas encaminadas a acrecentar el margen de negociación del precio de que dispone la entidad adjudicadora. Una de esas medidas puede ser exigirle que establezca el período de negociación en el pliego de condiciones.

²⁹ Párr. 2 del comentario de la Guía sobre la descripción general y las principales cuestiones de política de la solicitud de propuestas sin negociación y párr. 3 del comentario sobre los procedimientos de solicitud de propuestas con negociación consecutiva (artículo 50).

³⁰ Párrs. 4 a 7 del comentario sobre los procedimientos de solicitud de propuestas con negociación consecutiva (artículo 50).

La negociación competitiva

1. El reglamento de la contratación pública debe hacer hincapié en el carácter excepcional de este método de contratación, que podría preferirse en lugar de la contratación con un único proveedor o contratista, de ser posible, cuando se tratara de casos de urgencia, de sucesos catastróficos o de la protección de intereses esenciales de seguridad del Estado promulgante. No debe considerarse una variante de ningún otro método de contratación previsto en la Ley Modelo.
2. Se debe exigir a la entidad adjudicadora que, incluso en casos de urgencia, de sucesos catastróficos y de protección de intereses esenciales de seguridad del Estado promulgante, ante todo se plantee la posibilidad de recurrir a la licitación abierta o a cualquier otro método competitivo de contratación. Cuando llegue a la conclusión de que la aplicación de otros métodos competitivos no es viable, siempre deberá considerar la posibilidad de recurrir a la negociación competitiva, y no a la contratación con un único proveedor, a menos que llegue a la conclusión de que el caso es de suma urgencia o de que existe otro motivo concreto que justifique que se recurra a la contratación con un solo proveedor en virtud del párrafo 5 del artículo 30 de la Ley Modelo [\[**hiperenlace**\]](#) (como la falta de base competitiva o la existencia de derechos exclusivos).
3. Se deberían dar ejemplos de situaciones en que habría que emplear ese método de contratación, entre ellas la necesidad urgente de adquirir suministros médicos o de otra índole tras un desastre natural o la de reemplazar una pieza de un equipo común que haya dejado de funcionar. Debería explicarse que no se podrá recurrir a él si la urgencia obedece a una falta de planificación o a cualquier otro acto u omisión de la entidad adjudicadora. Debería precisarse que el alcance de la contratación que se realizara mediante este método ha de ser consecuencia directa de la propia urgencia. En otras palabras, si se necesita con urgencia una pieza de un equipo y se prevé que más adelante se van a necesitar más piezas de la misma clase, solo se podrá recurrir a la negociación competitiva para adquirir la que se necesite inmediatamente.
4. Se pueden imponer requisitos complementarios para el empleo de la negociación competitiva. Por ejemplo, puede exigirse que la entidad adjudicadora adopte las siguientes medidas: establecer normas y procedimientos básicos que rijan la negociación a fin de que se proceda con la debida eficiencia; preparar diversos documentos que sirvan de base a la negociación, en concreto, documentos en que se dé a conocer la descripción del objeto del contrato adjudicable y las cláusulas y condiciones contractuales correspondientes, y pedir a los proveedores o contratistas con los que negocie que desglosen sus precios para facilitar la comparación de las ofertas.
5. Una característica inherente a este método de contratación es la convocatoria directa dirigida a un número limitado de proveedores o contratistas elegidos por la entidad adjudicadora. Eso plantea cuestiones idénticas a las examinadas en la sección VI del presente documento en el contexto de la licitación restringida y la solicitud de propuestas, entre ellas las consecuencias de publicar un preaviso de la contratación, a saber, la aparición de proveedores o contratistas desconocidos que soliciten participar en la negociación competitiva y los mecanismos necesarios para

garantizar que no se haga discriminación al elegir a los concursantes. El reglamento debe abordar esas cuestiones también en el contexto de este método de contratación.

6. Deben examinarse las excepciones al requisito de publicar un preaviso de la contratación en el caso de la convocatoria directa, ya que son pertinentes en lo que respecta a las condiciones para recurrir a la negociación competitiva. La entidad adjudicadora no está obligada a publicar ese preaviso, pero podrá optar por hacerlo cuando recurra a la negociación competitiva en casos de urgencia. Procede publicar el preaviso cuando se emplee en contrataciones que entrañen la protección de intereses esenciales de seguridad del Estado, sin perjuicio de las excepciones que puedan aplicarse por razones de confidencialidad en virtud de una norma aplicable del Estado promulgante. Por ejemplo, en esa clase de contratación puede haber información reservada y la entidad adjudicadora puede estar autorizada u obligada (ya sea en virtud del régimen de la contratación pública o de otra norma aplicable del Estado promulgante) a abstenerse de anunciar públicamente la contratación. El reglamento debe establecer esa autorización o exigencia o remitirse a otra norma aplicable del Estado promulgante en que se establezca.

7. Se puede recomendar que se entablen negociaciones con tres proveedores o contratistas, como mínimo, para garantizar un proceso verdaderamente competitivo.

8. Debería explicarse el propósito y el carácter de las negociaciones sostenidas en el marco de este método de contratación, en particular, que pueden concernir a cualquiera de los aspectos de las propuestas y entrañar la negociación del precio, y que se celebran en forma concomitante, no consecutiva, como en el contexto de la solicitud de propuestas con negociación consecutiva.

9. Cabría remitirse a todas las salvaguardias establecidas en la Ley Modelo con objeto de garantizar transparencia y el trato justo, igualitario y equitativo de todos los participantes en el proceso de adjudicación. Además de las garantías mencionadas en la propia Ley Modelo concretamente en el contexto de este método de contratación (por ejemplo, los requisitos relacionados con la circulación de los documentos pertinentes y la información que se proporcione a los proveedores o contratistas participantes), está el requisito de que se lleve un expediente exhaustivo del proceso de contratación, con detalles sobre las negociaciones sostenidas con cada proveedor o contratista que haya participado y que se dé acceso a los concursantes a ese expediente, de conformidad con el artículo 25 [\[**hiperenlace**\]](#). Deberían disponerse otras salvaguardias, entre ellas la igualdad de oportunidades para negociar de todos los invitados a la negociación competitiva. También podrían disponerse medidas prácticas como la de garantizar que se examinara la misma cuestión con los participantes de forma concomitante durante el mismo tiempo y que en el pliego de condiciones se dieran a conocer las normas para establecer la secuencia de las reuniones que se celebrarían con los diferentes participantes, la duración máxima de la etapa de negociación y el marco cronológico de la negociación con cada uno de los proveedores o contratistas. Además, se podrían exigir medidas de supervisión como la presencia de personas ajenas a la estructura de la entidad adjudicadora durante la negociación que se encargaran de vigilar el proceso. Asimismo, se podría exigir que se estableciera un comité negociador y normas para su integración y su funcionamiento.

10. El reglamento debe prever medidas encaminadas a garantizar que todos los proveedores o contratistas participantes sean tratados en pie de igualdad por la

entidad adjudicadora. Esas medidas abarcan el requisito de que la entidad adjudicadora expida la solicitud de mejores ofertas definitivas por escrito y la comunique simultáneamente a todos los participantes, de manera que todos puedan recibir la información acerca de la terminación de las negociaciones y del tiempo disponible para preparar sus mejores ofertas definitivas.

11. Como ocurre con otros métodos de contratación que abarcan la etapa de presentación de las mejores ofertas definitivas, deben examinarse las diferencias entre la prohibición de entablar negociaciones después de la presentación de esas ofertas y la posibilidad de solicitar aclaraciones y explicaciones respecto de las condiciones de estas con arreglo al artículo 16 de la Ley Modelo **[**hiperenlace**]**.

La contratación con único proveedor o contratista

1. El reglamento de la contratación pública debe prever medidas para impedir que la entidad adjudicadora recurra a la contratación con un solo proveedor cuando se disponga de otros métodos de contratación.

2. Deben preverse las diferentes situaciones que dan lugar a que se aplique ese método, entre ellas, las siguientes: a) cuando no exista, objetivamente, otra alternativa, como en el caso de que haya un único proveedor o contratista capaz de suministrar el objeto del contrato adjudicable, ya sea porque goza de derechos exclusivos respecto de este o por otros motivos que confirmen esa exclusividad, y b) cuando la ley del Estado promulgante autorice o exija el empleo de ese método de contratación por otros motivos, por ejemplo, para aplicar su política socioeconómica o proteger los intereses esenciales de seguridad del Estado. De no existir esas razones objetivas por las que el empleo del método está autorizado, la razón para recurrir a él puede ser la falta de planificación apropiada o de capacidad de parte de la entidad adjudicadora para considerar y aplicar otros métodos o instrumentos.

3. Cuando se emplee la contratación con un único proveedor porque no hay otra opción, el reglamento debe establecer o analizar las medidas necesarias para comprobar que la razón invocada por la entidad adjudicadora para emplear el método sea realmente justificable de manera objetiva. Entre ellas cabe mencionar el requisito de dar un preaviso público oportuno de la contratación con un único proveedor como salvaguardia esencial; de esa manera se pone a prueba la presunción de la entidad adjudicadora de que existe un proveedor o contratista exclusivo y se refuerza así la transparencia y la rendición de cuentas en ese aspecto de la práctica de la contratación pública. El reglamento puede establecer un período mínimo para la publicación del preaviso antes de que pueda comenzar el proceso de contratación y exigir que se difunda lo más posible. Se debe disponer que, si surgen otros proveedores o contratistas, se lleve a cabo otro proceso de contratación mediante otro método, habida cuenta de que en ese caso ya no puede justificarse la contratación con un único proveedor o contratista. Cabe aplicar medidas para comprobar la manera en que se ha formulado la descripción del objeto del contrato adjudicable (podría formularse en un sentido tan estricto como para limitar artificialmente el mercado de que se trate a un solo proveedor o contratista; eso puede fomentar, con intención o sin ella, los monopolios y la corrupción). Por esa

razón, podría promoverse el uso de descripciones funcionales (con especificaciones de la ejecución y del producto).

4. Si la ley del Estado promulgante autorizara o exigiera recurrir a la contratación con un único proveedor o contratista por otros motivos, en el reglamento se debería explicar la aplicación de la condición pertinente para emplearla y sus límites, entre ellos los siguientes:

a) En el contexto de la condición establecida en el apartado b) del artículo 30.5 de la Ley Modelo, la extrema urgencia, puede explicarse que la urgencia debe ser tan extrema como para que no sea viable entablar negociaciones con más de un proveedor o contratista y, por ende, tampoco lo sea recurrir a la negociación competitiva. Como sucede con esta última, la necesidad de vincular el alcance de la contratación al grado de suma urgencia limitará la cuantía de lo que pueda contratarse utilizando ese método: la cuantía de un contrato adjudicado en una situación de emergencia debería limitarse estrictamente a las necesidades que surgieran de resultados de esa situación. Por ejemplo, tras una catástrofe puede haber necesidades inmediatas de agua potable y suministros médicos; también podrían necesitarse instalaciones semipermanentes de cobijo debido a la misma catástrofe, pero eso tal vez no sea tan urgente y podría adquirirse por otros métodos;

b) En el contexto de la condición establecida en el apartado c) del artículo 30.5, la necesidad de normalización o de compatibilidad con los bienes, el equipo, la tecnología o los servicios ya existentes, el reglamento debe disponer que en esas situaciones haya que limitarse únicamente a adjudicar contratos de escasa importancia durante un breve período. También debería hacerse hincapié en que esa razón debe ser verdaderamente excepcional, ya que de otro modo podrían invocarse necesidades que en realidad obedecieran a la deficiente planificación de la contratación por parte de la entidad adjudicadora;

c) En el contexto de la condición establecida en el apartado d) del artículo 30.5, la protección de los intereses esenciales de seguridad del Estado, debe explicarse que recurrir a la contratación con un solo proveedor, en lugar de aplicar otro método de contratación, sería apropiado únicamente si hubiese información reservada y la entidad adjudicadora llegara a la conclusión de que esa información no estaría suficientemente protegida si se empleara cualquier otro método de contratación, incluso otro método excepcional como la negociación competitiva. Como se indicó en la sección II.B del presente documento, la facultad otorgada a las entidades adjudicadoras para adoptar medidas especiales e imponer requisitos especiales a fin de proteger la información reservada es aplicable únicamente en la medida en que lo permitan el reglamento de la contratación pública u otras normas jurídicas pertinentes del Estado promulgante;

d) En el contexto de la condición establecida en el apartado e) del artículo 30.5, la promoción de alguna política socioeconómica del Estado promulgante, debe reglamentarse exhaustivamente el proceso de solicitar y recibir comentarios con objeto de validar la oportunidad de hacerlos. Debería establecerse el contenido mínimo del preaviso, en particular en lo que respecta a la cuestión de determinar si se dispone de un solo proveedor o contratista, de manera que se prevenga el abuso de esa clase de contratación en favor de un proveedor o contratista en particular. También deberían reglamentarse otros aspectos de esas disposiciones, en especial, quiénes deberían hacer comentarios (por ejemplo, las

comunidades locales) y la finalidad o el efecto de los comentarios que se recibiesen, especialmente si fuesen desfavorables. Debería exigirse a la entidad adjudicadora que dejara transcurrir suficiente tiempo entre el aviso público de la contratación y el comienzo del proceso de contratación como para analizar los comentarios formulados por cualquier particular y dejar constancia de ellos, así como para ofrecer explicaciones a quienes las solicitaran. Si se promulgan las disposiciones por las que se exige un mecanismo de aprobación previa de la contratación con un único proveedor o contratista por ese motivo³¹, se deben regular las prerrogativas de la autoridad encargada de aprobarla, en particular si esas prerrogativas quedarán sin efecto una vez que autorice a la entidad adjudicadora a recurrir a ese método, o si seguirá ejerciendo alguna clase de supervisión del modo en que se lleve a cabo el procedimiento. Al respecto, debería prestarse atención especial a la necesidad de evitar los conflictos de intereses en esa etapa y en etapas posteriores del proceso de contratación, si, por ejemplo, la misma entidad aprobara el empleo del método y posteriormente la entrada en vigor del contrato, o si entendiera de las demandas que se pudieran entablar más adelante en el curso del proceso de contratación.

5. Si la razón para recurrir a la contratación con un único proveedor o contratista es la falta de planificación apropiada o de capacidad de la entidad adjudicadora para considerar y utilizar otros métodos o instrumentos, deben abordarse esas razones estableciendo medidas para la debida planificación del proceso y la creación de la capacidad necesaria para considerar y utilizar otras opciones. Por ejemplo, mediante un acuerdo marco cerrado sin segunda etapa competitiva se puede hacer frente eficazmente a esas situaciones de suma urgencia, siempre y cuando el acuerdo se haya concertado anteriormente previendo la posibilidad de que la necesidad se planteara de forma periódica o en un determinado margen cronológico. Se podrían concertar acuerdos marco abiertos para la adquisición de productos estándar sencillos y acuerdos marco cerrados para la de productos más complejos, si se previeran necesidades apremiantes o la adquisición de suministros complementarios del mismo proveedor por razones de normalización y compatibilidad. Podría recurrirse a la solicitud de cotizaciones y a las subastas electrónicas inversas, en lugar de a la contratación con un único proveedor o contratista, si surgiera la necesidad de adquirir productos comunes en situaciones de urgencia o emergencia o productos que entrañaran la necesidad de proteger intereses esenciales de seguridad del Estado promulgante. Cuando sea necesario entablar negociaciones, pero no se pueda recurrir a otro método más estructurado y transparente, deberá recurrirse a la negociación competitiva. Eso se debe a que ese método, por definición, es más competitivo que la contratación con un solo proveedor y a que en las disposiciones de la Ley Modelo que regulan el proceso de negociación competitiva se establecen más salvaguardias, razón por la cual este es más estructurado y transparente que el de la contratación con un solo proveedor.

6. La convocatoria directa es una característica inherente a ese método de contratación pública, ya que en él la convocatoria se dirige a un solo proveedor o contratista elegido por la entidad adjudicadora. Esto plantea cuestiones idénticas a las examinadas en la sección VI del presente documento en el contexto de la licitación restringida y la solicitud de propuestas, entre ellas las consecuencias de la publicación de un preaviso de la contratación, a saber, que surjan concursantes

³¹ Al respecto, véase el párr. 8 del comentario de la Guía sobre las condiciones de empleo de la contratación con un único proveedor o contratista (artículo 30.5).

desconocidos que impugnen el empleo de la contratación con un único proveedor o contratista, examinada también anteriormente en el párrafo 3. El reglamento debe abordar esas cuestiones también en el contexto de ese método de contratación.

7. Deben examinarse las excepciones al requisito de publicar un preaviso de la contratación en el caso de la convocatoria directa, ya que son pertinentes en lo que respecta a algunas de las condiciones para recurrir a la contratación con un único proveedor o contratista. La entidad adjudicadora no está obligada a publicar ese preaviso, pero podrá optar por hacerlo cuando se recurra a la contratación con un solo proveedor en situaciones de extrema urgencia. Procederá publicar el preaviso cuando se recurra a ella para adjudicar contratos que entrañen la protección de intereses esenciales de seguridad del Estado, sin perjuicio de las excepciones que puedan aplicarse por razones de confidencialidad con arreglo a la ley del Estado promulgante. Por ejemplo, en esos casos también puede haber información reservada y la entidad adjudicadora puede estar autorizada u obligada (ya sea en virtud del régimen de la contratación pública o de otra norma aplicable del Estado promulgante) a abstenerse de anunciar públicamente la contratación. El reglamento de la contratación pública debe establecer esa autorización o exigencia o remitirse a otra norma aplicable del Estado promulgante en que se establezca.

8. Cabría remitirse a todas las salvaguardias establecidas en la Ley Modelo con objeto de garantizar transparencia en el proceso regido por ese método de contratación pública, entre ellas el requisito de publicar un preaviso de la contratación, el de publicar avisos de los contratos adjudicados y el de llevar un expediente exhaustivo del proceso de contratación, en el que también se deje constancia de las razones que justifiquen la aplicación de ese método.

VIII. Temas que deberán tratarse en el reglamento de la contratación pública en el contexto de las subastas electrónicas inversas (artículo 31 y Capítulo VI de la Ley Modelo (Subasta electrónica inversa) **[hiperenlaces**]**)**

Observaciones generales

1. En el reglamento de la contratación pública deben explicarse las características principales de las subastas electrónicas inversas y destacarse sus principales diferencias con respecto a las subastas tradicionales (por ejemplo, que son subastas en línea con evaluación automática en las que puede respetarse el anonimato de los participantes y garantizarse la confidencialidad y trazabilidad del proceso y que siempre deben utilizarse como etapa final del procedimiento de contratación, antes de la adjudicación del contrato). Al respecto, debería recurrirse a la definición de la subasta electrónica inversa que figura en el artículo 2 de la Ley Modelo y a las observaciones generales de la Guía sobre el Capítulo VI **[**hiperenlaces**]**. A fin de evitar confusiones e interpretaciones inconvenientes, se debería explicar, en particular, que la expresión “ofertas cada vez más bajas” utilizada en la definición de subasta electrónica inversa se refiere a rebajas del precio o mejoras sucesivas de las ofertas que se presenten en general a la entidad adjudicadora.

2. Las cuestiones relativas a la autenticidad e integridad de los datos, la seguridad y los aspectos conexos correspondientes al empleo de métodos de contratación electrónica que se mencionaron anteriormente, en el contexto de los artículos 7 y 40, y en la Guía son particularmente pertinentes en el contexto de las subastas electrónicas inversas, ya que estas, por definición y de conformidad con la Ley Modelo, se celebran en línea. Por consiguiente, en el reglamento se deben abordar cuestiones de carácter técnico como la necesidad de disponer de infraestructura apropiada, la de ofrecer acceso a sitios web pertinentes que dispongan de una amplitud de banda suficiente y las medidas de seguridad apropiadas para conjurar el mayor riesgo de que los concursantes se enteren sin autorización de información comercialmente delicada sobre sus competidores.

3. Deben regularse los aspectos técnicos de la subasta que se han de comunicar en el pliego de condiciones para hacer saber sus características informatizadas y para garantizar la transparencia y previsibilidad del proceso (como las especificaciones de la conexión, el equipo que se utilizará, el sitio web, el programa informático de que se trate, las características técnicas y, si procede, la capacidad necesaria). Debe exigirse a la entidad adjudicadora que prepare normas de procedimiento para cada subasta electrónica inversa. Se pueden formular o exigir que se formulen normas uniformes que puedan utilizar las entidades adjudicadoras para adaptarse a los requisitos de cada contratación. En ellas deben precisarse, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) La clase de información que se revelará a los participantes durante la subasta y cómo y cuándo se les dará a conocer (por lo menos, y a fin de garantizar un trato justo, igualitario y equitativo, debería comunicarse la misma información simultáneamente a todos ellos);

b) Los criterios y procedimientos previstos para toda eventual prórroga del plazo para presentar ofertas;

c) Las circunstancias que exigirían suspender o dar por terminada la subasta;

d) Las salvaguardias procesales para proteger los intereses de los participantes si se suspende o se da por terminada la subasta, entre ellas la notificación inmediata y simultánea a todos los participantes de la suspensión o terminación y, en caso de suspensión, la fecha de reapertura de la subasta y el nuevo plazo para su clausura. Cuando se dé por terminada una subasta electrónica inversa empleada como método autónomo de contratación, el reglamento debería determinar si la terminación necesariamente cancela la subasta, o si se puede adjudicar el contrato sobre la base de los resultados obtenidos hasta el momento de la terminación;

e) Los criterios permisibles que rigen la clausura de la subasta, entre ellos, los siguientes: i) cuando haya pasado la fecha y hora fijadas para la clausura de la subasta; ii) cuando la entidad adjudicadora, dentro de un plazo determinado, no haya recibido más precios ni valores nuevos y válidos que mejoren la oferta con la puntuación más alta, o iii) cuando se haya concluido el número de etapas de la subasta establecido en el anuncio correspondiente. También debería aclararse que cada uno de esos criterios puede entrañar la obligación de presentar otra información previamente; en las orientaciones se debería profundizar sobre la clase de información que cabría presentar. Por ejemplo, con respecto al punto ii), habría que indicar cuánto tiempo se dejará transcurrir tras recibir la última oferta para clausurar

la subasta. Con respecto al punto iii), habría que informar por adelantado si la subasta constará de una o de varias etapas (en ese último caso, se debería indicar el número y la duración de estas, así como lo que se prevé que ocurrirá al final de cada una, por ejemplo, si se previera la exclusión de licitantes al final de cada etapa);

f) Los procedimientos que habrán de aplicarse en caso de avería, mal funcionamiento o fallo total del sistema utilizado en la subasta;

g) En lo que concierne a las condiciones en que los licitantes podrán presentar ofertas, toda mejora mínima del precio u otros valores al presentar una nueva oferta durante la subasta, o cualquier limitación al respecto. En este último caso, se deben explicar esas limitaciones (que pueden ser inherentes a las características técnicas de los bienes por adquirir).

4. Debe exigirse una planificación más detallada que en otros métodos de contratación, habida cuenta de la necesidad de establecer una fórmula matemática para elegir al ganador y de preparar normas detalladas de procedimiento.

5. Deberían establecerse o exigirse mecanismos para que la entidad adjudicadora observara la competitividad de los mercados en que se utilizan técnicas como la subasta electrónica inversa. El reglamento de la contratación pública debería exigir que la entidad adjudicadora dispusiera de información especializada fidedigna sobre operaciones similares anteriores, el mercado correspondiente y su estructura. Debería exhortarse a modificar los procedimientos en las contrataciones reiteradas en que participara el mismo pequeño grupo de licitantes en subastas electrónicas inversas y si hubiera indicios de manipulación de los resultados de las subastas por parte de los licitantes.

Artículo 31. Condiciones de empleo de la subasta electrónica inversa

[hiperenlace**]**

1. El reglamento de la contratación pública debería ayudar a la entidad adjudicadora a determinar las circunstancias en las cuales sería conveniente y apropiado llevar a cabo una subasta electrónica inversa. Se debería orientar a la entidad adjudicadora en lo que respecta a investigar el mercado pertinente antes de iniciar un proceso de contratación a fin de determinar las ventajas y desventajas relativas de la subasta electrónica inversa en un caso en particular, y debería alentarse el uso de una terminología común para describir el objeto del contrato adjudicable, ya sea mediante códigos o remitiéndose a normas generales del mercado. Cabe destacar que la subasta electrónica inversa se presta más para la adquisición de bienes y servicios utilizados comúnmente que, por lo general, se venden en un mercado amplio y sumamente competitivo. En esos casos, la entidad adjudicadora puede hacer una descripción detallada o una descripción basada en normas industriales y las ofertas que se presenten tendrán las mismas características técnicas y de calidad. Puede tratarse de suministros de oficina, productos básicos, equipo informático estándar, material básico de construcción y servicios sencillos. No es necesario emprender un proceso de evaluación complicado; los gastos posteriores a la adquisición suelen ser limitados o incluso nulos, y no cabe prever ningún servicio ni beneficios añadidos una vez concluida la ejecución del contrato inicial. Las clases de contratos en que los factores cualitativos pesen más que las consideraciones de precio y cantidad, entre ellos, los de construcción o de servicios de consultores (por ejemplo, de servicios de asesoramiento) y todo otro contrato en

que la calidad sea un factor determinante, no se prestan para la subasta electrónica inversa.

2. El reglamento de la contratación pública puede restringir el empleo de la subasta electrónica inversa -tal vez de manera provisional y en la medida en que lo permita el régimen de la contratación pública- a los mercados notoriamente competitivos (por ejemplo, aquellos en que haya una cantidad suficiente de licitantes como para garantizar la libre competencia y el respeto del anonimato de estos) o imponiendo restricciones cualitativas como la de que se limite a la adquisición de bienes únicamente, ya que en ese caso las estructuras de costos pueden ser más fáciles de discernir. Pueden ofrecerse listas ilustrativas de productos que se puedan adquirir mediante subastas electrónicas inversas; otra posibilidad sería enumerar las características genéricas que debería reunir un producto determinado para que se pudiera adquirir o no mediante esa técnica de contratación.

3. Se pueden establecer otras condiciones de empleo de la subasta electrónica inversa que sean admisibles con arreglo a la ley aplicable, por ejemplo, la de agrupar las adquisiciones con miras a amortizar los gastos que entraña el establecimiento del sistema utilizado para celebrarla, entre ellos los de contratación de servicios informáticos externos y de proveedores de servicios. También puede impartirse orientación acerca del concepto de “criterio del precio” sobre la base de las disposiciones del artículo 11 y el comentario correspondiente **[**hiperenlaces**]**. Al respecto, debería explicarse que cuando se utilicen criterios distintos del precio para determinar la oferta ganadora, esos criterios deben ser cuantificables y deben poder expresarse en unidades monetarias (por ejemplo, en cifras o porcentajes); esta disposición invalida la reserva formulada en el artículo 11 en el sentido de que los criterios deberán expresarse en unidades monetarias “en la medida de lo posible”. Si bien en teoría todos los criterios pueden expresarse de esa manera, como se observa en la Guía en la introducción del Capítulo I, se obtendrá un resultado óptimo si los criterios de evaluación pueden expresarse objetivamente y de manera demostrable en esos valores.

Artículo 53. La subasta electrónica inversa como método de contratación en sí **[hiperenlace**]****

1. El reglamento de la contratación pública debería ayudar a la entidad adjudicadora a establecer las circunstancias en las cuales sería necesario determinar la idoneidad de los participantes o examinar o evaluar las ofertas iniciales antes de la subasta. Por ejemplo, cuando el objeto del contrato adjudicable sea un bien de uso común, casi no existen riesgos de que las ofertas no resulten ser conformes y los licitantes no resulten ser idóneos. Así pues, prácticamente no hay necesidad de aplicar esas medidas de control. En esos casos puede bastar con una declaración de los proveedores o contratistas antes de la subasta (por ejemplo, en el sentido de que poseen la necesaria idoneidad y entienden el carácter del objeto del contrato adjudicable y pueden entregarlo). En otros casos puede ser necesario determinar la conformidad de las ofertas antes de proceder a la subasta (por ejemplo, cuando únicamente se admitan a participar en ella a los proveedores o contratistas que puedan entregar automóviles con un nivel máximo predeterminado de emisiones) y, por consiguiente, se necesitarán ofertas iniciales. En algunos de esos casos la entidad adjudicadora tal vez desee calificar a los proveedores o contratistas que presenten ofertas iniciales conformes antes de la subasta (en el ejemplo señalado,

los proveedores o contratistas cuyas ofertas iniciales se ajusten al límite establecido recibirán una puntuación basada en los niveles de emisión de gases), a fin de establecer su posición relativa y en qué medida deben mejorar sus ofertas durante la subasta para aumentar sus posibilidades de ganar. En esos casos la subasta debe ir precedida de una evaluación de las ofertas iniciales.

2. Se deberían establecer los requisitos que deben incluirse en el pliego de condiciones además de los enumerados en el artículo. Si esos requisitos figuran en otras normas aplicables del Estado promulgante, el reglamento debería remitirse a ellas.

3. Como se destacó en la sección IV del presente documento, el reglamento debe determinar el medio y la forma de publicación de la invitación a la subasta, que podrá ser incluso a nivel internacional, lo que garantizará que llegue a conocimiento efectivamente de los proveedores o contratistas que se encuentren en el extranjero.

4. En lo que respecta al artículo 53.4, para facilitar la consulta deberían enumerarse todos los motivos que pueden darse para rechazar las ofertas iniciales, entre ellos los enunciados en el artículo 9 como motivos para la descalificación, en el artículo 10, relativo a los criterios para la conformidad de las ofertas, en el artículo 20, relativo al rechazo de las ofertas anormalmente bajas, y en el artículo 21, relativo a la exclusión de un proveedor o contratista por haber ofrecido algún incentivo, por gozar de alguna ventaja competitiva desleal o por adolecer de algún conflicto de intereses **[**hiperenlace**]**.

Artículo 54. La subasta electrónica inversa como fase previa a la adjudicación del contrato **[hiperenlace**]****

En el reglamento de la contratación pública se deberían enumerar todos los casos en que podría cancelarse la subasta electrónica inversa que se hubiera anunciado como método para seleccionar al proveedor o contratista ganador al comienzo del proceso de contratación, por ejemplo, cuando el número de participantes en la subasta fuese insuficiente para garantizar una verdadera competencia (artículo 55.2) o cuando existiera peligro de colusión, por ejemplo, si el anonimato de los licitantes se hubiese visto comprometido en una etapa anterior del procedimiento de contratación (en el artículo 19 **[**hiperenlace**]** se permite a la entidad adjudicadora cancelar el procedimiento de contratación, y el riesgo de colusión podría invocarse como motivo para cancelar la subasta electrónica inversa y el proceso en su totalidad).

Artículo 55. Inscripción para participar en la subasta electrónica inversa y plazo para la apertura de la subasta **[hiperenlace**]****

1. En el reglamento de la contratación pública debe figurar una lista exhaustiva de las circunstancias que justificarían que se procediera a celebrar la subasta aunque el número de participantes inscritos no bastara para garantizar un proceso verdaderamente competitivo. Las disposiciones del artículo no son prescriptivas al respecto, sino que se otorga a la entidad adjudicadora la facultad de decidir si en esas circunstancias ha de cancelarse la subasta. Como la decisión de no cancelarla puede ser incompatible con el objetivo general de fomentar la competitividad y evitar la colusión, solo se justificaría en los casos realmente excepcionales en que la contratación debiera proseguir aunque no fuera realmente competitiva.

2. En lo que concierne a las subastas electrónicas inversas que constituyan una etapa de otros métodos o técnicas de contratación, puede preverse la opción de que la entidad adjudicadora estipule en el pliego de condiciones que el contrato podrá adjudicarse sobre la base de las ofertas iniciales. Puede considerarse la posibilidad de aplicar esa opción, en lugar de tener que cancelar la contratación, cuando el número de participantes restantes en el proceso de adjudicación no baste para garantizar la competitividad efectiva durante la subasta o cuando pueda haber colusión.

Artículo 56. Condiciones exigibles en el curso de la subasta electrónica inversa

[hiperenlace**]**

1. El reglamento de la contratación pública debe prohibir que se revele la identidad de los licitantes durante la subasta y después de esta, incluso si se da por finalizada o se suspende. Debe prohibirse tanto la divulgación explícita como la indirecta en todas sus formas y deben darse ejemplos de casos de divulgación indirecta que estén comprendidos en la prohibición.

2. Debe exigirse que los encargados de manejar el sistema de la subasta en nombre de la entidad adjudicadora estén obligados por las normas de procedimiento pertinentes, en particular en lo que respecta a no revelar la identidad de los licitantes antes, en el curso y después de la subasta.

Artículo 57. Condiciones exigibles después de la subasta electrónica inversa

[hiperenlace**]**

1. El reglamento de la contratación pública debe proporcionar orientación a la entidad adjudicadora con respecto a las opciones de que dispone con arreglo al artículo si el licitante ganador resulta no ser idóneo, o si su oferta resulta no ser conforme o es rechazada por ser anormalmente baja: cancelar el procedimiento de contratación o adjudicar el contrato al siguiente licitante ganador. Debería exigirse a la entidad adjudicadora que evaluara las consecuencias de cancelar la subasta y que determinara, en particular, si sería posible celebrar una segunda subasta durante el mismo procedimiento de contratación y el costo que entrañaría la aplicación de otro método. En particular, puede haber quedado comprometido el anonimato de los licitantes y también estar en peligro toda posible reapertura del proceso competitivo. No obstante, esos riesgos no deberían obligar a la entidad adjudicadora a optar siempre por la siguiente oferta ganadora. Puede ser necesario cancelar la subasta, por ejemplo, cuando se sospeche que ha habido colusión entre el licitante ganador y el que le sigue, ya que eso puede desembocar en la aceptación de una oferta con un precio anormalmente alto.

2. Debe exigirse que se adopten medidas inmediatamente después de la subasta, en estricto cumplimiento de las disposiciones aplicables de la Ley Modelo, a fin de lograr que el resultado final se determine en el plazo más breve que sea razonablemente viable. Las medidas enunciadas en el artículo no deberían considerarse una oportunidad para socavar la determinación automática de la oferta ganadora. En consecuencia, se debe exigir a la entidad adjudicadora que haga constar en el expediente los detalles de los procedimientos previstos en el artículo, si efectivamente se han aplicado, así como las decisiones que haya adoptado al respecto y las razones para hacerlo.

IX. Temas que deberán tratarse en el reglamento de la contratación pública en el contexto del procedimiento del acuerdo marco (artículo 32 y Capítulo VII de la Ley Modelo (Condiciones de empleo del procedimiento del acuerdo marco) [hiperenlaces**])**

Observaciones generales

1. En el reglamento se debe aclarar el carácter que revisten los acuerdos marco en el Estado promulgante. El acuerdo marco no es un contrato adjudicable conforme a la definición de la Ley Modelo, pero puede ser un contrato ejecutable en el Estado promulgante. En consecuencia, en el reglamento de la contratación pública o en otras normas aplicables de los Estados promulgantes deberán abordarse cuestiones como la eficacia del acuerdo con arreglo al derecho de los contratos. En particular, debe aclararse si el gobierno está obligado a hacer uso del acuerdo marco y en qué medida las ofertas presentadas en la primera etapa de este método pueden ser vinculantes con arreglo al ordenamiento jurídico interno del Estado promulgante. En el caso de un acuerdo marco abierto, en el reglamento se debe aclarar que los proveedores o contratistas que pasen a ser parte en el acuerdo después de su concertación inicial deberán quedar obligados por sus cláusulas en el momento de hacerlo.

2. Debe explicarse el vínculo que existe entre las circunstancias de la contratación y las diversas decisiones que han de adoptarse en relación con el empleo del procedimiento del acuerdo marco, entre otras cosas, en particular, si procede recurrir a este, la clase de acuerdo marco que ha de concertarse, el alcance del acuerdo, el número de proveedores o contratistas que pasen a ser parte y el papel del organismo encargado de las adquisiciones centralizadas, si lo hubiera.

3. En lo que respecta a la clase de acuerdo marco que ha de concertarse, se debe explicar la manera de elegir entre las clases de acuerdos previstos por la ley teniendo en cuenta las diferentes maneras en que funciona la competitividad en cada una de ellas. El grado de precisión con que pueda y deba definirse la necesidad de proceder a la contratación en la primera etapa dictará el grado de competitividad que es posible y conveniente en la segunda etapa. Si es posible definir con precisión esa necesidad y si esta no varía en el curso del acuerdo, un acuerdo marco cerrado sin una segunda etapa competitiva, en el que el o los proveedores o contratistas ganadores en relación con todos o algunos de los productos se determinen en la primera etapa, hará que el proceso adjudicatorio resulte lo más competitivo posible en la primera etapa y redundará en las mejores ofertas. Ahora bien, ese método es inflexible y exige una planificación precisa. Una normalización rígida puede ser difícil o inapropiada, especialmente en el contexto de las adquisiciones centralizadas, en que las necesidades de cada entidad adjudicadora pueden variar y puede ser apropiado ajustar los requisitos, de modo que las necesidades se expresan con menos precisión en la primera etapa, así como en mercados inciertos (como la contratación de emergencia futura). Si las necesidades de la entidad adjudicadora tal vez no varíen, pero el mercado es dinámico y volátil, será conveniente proceder a una segunda etapa competitiva, a menos que la cuestión de la volatilidad se haya previsto en el acuerdo marco (por ejemplo, mediante un mecanismo de ajuste del

precio). Cuanto mayor sea el alcance de la segunda etapa competitiva, más compleja desde el punto de vista administrativo y más prolongada será, y menos previsibles serán las ofertas de la primera etapa en cuanto al resultado final, lo que puede dificultar la presupuestación eficaz. Si se va a proceder a una amplia segunda etapa competitiva, también puede tener poco sentido garantizar una competitividad rigurosa en la primera etapa; puede bastar con evaluar la idoneidad de los concursantes y la conformidad de las ofertas.

4. Una cuestión conexa que debe regularse es la de optar por concertar un acuerdo marco con un solo proveedor o con varios proveedores. Por razones de eficiencia administrativa suele ser conveniente concertarlo con varios proveedores, si bien las características del mercado de que se trate pueden hacer que resulte más ventajoso concertarlo con uno solo (por ejemplo, por razones de confidencialidad o de seguridad del abastecimiento, o por haber un solo proveedor o contratista en el mercado). Por otra parte, concertar un acuerdo marco cerrado con un único proveedor puede dar lugar a importantes descuentos acumulados a largo plazo, habida cuenta de la probable envergadura del negocio potencial para ese único proveedor o contratista, en particular si las necesidades de la entidad adjudicadora constituyen un porcentaje considerable del mercado, y siempre y cuando exista suficiente certeza de las cantidades que se adquirirán en el futuro (por ejemplo, mediante compromisos vinculantes de la entidad adjudicadora). Esa clase de acuerdo también puede reforzar la seguridad del abastecimiento, en la medida en que sea probable que el proveedor o contratista en cuestión pueda atender a todas las necesidades. Los acuerdos marco con varios proveedores, que son más comunes, son apropiados cuando al principio no se sabe quién va a ser el proveedor o contratista que presentará la mejor oferta en la segunda etapa, especialmente si se espera que las necesidades varíen o se ajusten en la segunda etapa mientras esté vigente el acuerdo marco, y cuando se trate de mercados volátiles y dinámicos. También permiten realizar adquisiciones centralizadas y, además, pueden garantizar el suministro cuando haya dudas acerca de la capacidad de un único proveedor para atender a todas las necesidades.

5. Debería hacerse hincapié en que una buena planificación de la contratación es esencial para establecer un acuerdo marco eficaz: los acuerdos marco no han de utilizarse como alternativa en lugar de planificar la contratación. Se requiere una planificación eficaz en las dos etapas del procedimiento de acuerdo marco. Sin ella no puede elegirse la clase apropiada de acuerdo, ni concluirse ningún acuerdo provechoso, ni garantizarse su funcionamiento efectivo. Debería destacarse que el propio acuerdo deberá ser completo, ya que en él no solo se deberán enunciar todas las condiciones contractuales, sino que también deberá hacerse una descripción del objeto del contrato (incluidas las especificaciones) y deberán establecerse los criterios de evaluación aplicables con miras a fomentar tanto la participación en el procedimiento que se vaya abrir como su transparencia, así como debido a las restricciones que existen para modificar las condiciones en el curso del acuerdo.

6. Pueden exigirse medidas encaminadas a garantizar la creación de suficiente capacidad como para adoptar decisiones acertadas, teniendo en cuenta que puede necesitarse más capacidad para gestionar los acuerdos marco eficazmente que para aplicar algunos de los métodos y técnicas previstos en la Ley Modelo, y que la formación y demás medidas de creación de capacidad serán esenciales para lograr que los acuerdos se utilicen bien y arrojen buenos resultados.

7. También deberían abordarse cuestiones como la vigilancia del funcionamiento de los acuerdos marco con objeto de determinar su eficacia en el contexto de cada proceso de adjudicación y en el mercado de la contratación pública en general (si se hacen realidad los beneficios previstos en materia de eficiencia administrativa y rentabilidad financiera), el efecto que puedan tener en la competitividad en el mercado de que se trate, especialmente cuando exista el riesgo de generar un mercado monopolístico u oligopolístico, y el cumplimiento de las salvaguardias previstas en la Ley Modelo para garantizar la transparencia, competitividad y objetividad del procedimiento. También habrá que vigilar la actuación de cada entidad adjudicadora que recurra al acuerdo marco y los resultados de este en lo que respecta a los precios, en comparación con los precios del mercado, en cada contratación. El uso inapropiado o erróneo del acuerdo por parte de una o dos entidades adjudicadoras puede dar lugar al aumento del precio o a la reducción de la calidad de las ofertas.
8. Si el Estado promulgante exige o promueve (o tiene la intención de promover) la gestión de todos los acuerdos marco por vía electrónica, el reglamento puede exigir que todos ellos se mantengan en un lugar centralizado, lo que también contribuye a aumentar la transparencia y eficiencia de su gestión y facilita la vigilancia.

Artículo 32. Condiciones de empleo del procedimiento del acuerdo marco

[hiperenlace**]**

1. El reglamento de la contratación pública debería ayudar a la entidad adjudicadora a determinar las circunstancias en las cuales sería conveniente y apropiado recurrir al procedimiento del acuerdo marco. Deberían establecerse medidas para aumentar la objetividad en la adopción de decisiones sobre el empleo del procedimiento y la elección de la clase de acuerdo y para poder determinar con más facilidad si las decisiones adoptadas son razonables en las circunstancias que rodeen a un acuerdo marco determinado.
2. La primera circunstancia que se prestaría para emplear un acuerdo marco se plantea cuando “se prevé” que la necesidad de la entidad adjudicadora surgirá “con una frecuencia indeterminable o reiterada”. Debería explicarse que esas dos últimas condiciones no tienen por qué ser simultáneas, aunque en la práctica suelen serlo. La segunda circunstancia se plantea cuando el objeto del contrato adjudicable resulta “urgentemente necesario”. Referirse a una necesidad indefinida, es decir, a que el plazo y el volumen de la contratación, e incluso la necesidad de adquirir el objeto del contrato adjudicable son inciertos, puede prestarse para que el acuerdo marco se utilice con miras a garantizar el suministro y previendo contratos reiterados. También debería aclararse el término “prevé” y la manera de determinar objetivamente el grado de probabilidad de la necesidad prevista. Los gastos administrativos del procedimiento en dos etapas se amortizarán debido al mayor número de adquisiciones, es decir, cuantas más veces se utilice el acuerdo marco, en el caso de procedimientos reiterados. Cuando se trate de adquisiciones indefinidas, esos gastos deben establecerse en función de la probabilidad de que surja la necesidad de adquirir los productos y de la seguridad que ofrezca el acuerdo marco (por ejemplo, fijando los precios y estipulando las condiciones por adelantado).
3. Pueden darse ejemplos de los productos que podrían adquirirse recurriendo al procedimiento del acuerdo marco: productos básicos como artículos de oficina,

piezas de repuesto y el suministro y mantenimiento de material informático. En esos casos el mercado puede ser sumamente competitivo y suelen realizarse compras regulares o reiteradas, pero de cuantía variable. Esos acuerdos también resultan adecuados para negociar la prestación de ciertos servicios, como el suministro de energía eléctrica, por más de una fuente de abastecimiento y para adquirir productos que se pueden necesitar en el futuro con urgencia, como medicamentos (en ese caso un objetivo importante es evitar precios exorbitantes y artículos de mala calidad de resultados de contratar con un solo proveedor en situaciones urgentes y de emergencia). En esos casos puede ser necesario garantizar el abastecimiento, así como también cuando se han de adquirir ciertos productos especiales que exigen una cadena de producción establecida, lo que hace conveniente recurrir a los acuerdos marco.

4. También pueden darse ejemplos de contratos en los que no procedería emplear el procedimiento del acuerdo marco: los contratos complejos en que las condiciones contractuales (incluidas las especificaciones) varían de un contrato a otro, o en que cabe esperar que varíen antes de la adjudicación del contrato; por ejemplo, los grandes contratos de inversión o de gran volumen de capital, o que entrañan productos sumamente técnicos o especializados y servicios más complejos, por lo general no se prestarían para aplicar el procedimiento del acuerdo marco.

Contratación con arreglo a un acuerdo marco cerrado y condiciones para adjudicar contratos con arreglo a un acuerdo marco cerrado (artículos 58 y 59 [hiperenlaces**])**

Contratación con arreglo a un acuerdo marco cerrado

1. En el reglamento de la contratación pública debe impartirse orientación a la entidad adjudicadora con respecto a la elección de un método para contratar con arreglo a un acuerdo marco cerrado teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 28 de la Ley Modelo [**hiperenlace**]. La importancia de que se mantenga una rigurosa competitividad en la primera etapa de un procedimiento basado en un acuerdo marco cerrado significa que el reglamento debe establecer la licitación abierta como método supletorio para la contratación con arreglo a esa clase de acuerdos. Deberían impartirse directrices claras con respecto a la aplicación de excepciones a la licitación abierta y debería preverse un mecanismo para examinar a fondo la aplicación de esas excepciones, en particular teniendo presentes los riesgos que pueden plantearse para la competitividad en la contratación con arreglo a los acuerdos marco y los tipos de compras para los que resulten adecuados. Deberían darse ejemplos de casos en los que es apropiado emplear algún método distinto de la licitación abierta; entre ellos cabe citar la aplicación de acuerdos marco para la adquisición rápida y económica de productos de bajo costo, productos que se adquieran reiteradamente y productos que puedan pasar a ser urgentemente necesarios, como los servicios de mantenimiento o de limpieza (para cuya adquisición puede no resultar económico recurrir a la licitación abierta), así como para la adquisición de productos especiales, como medicamentos, el suministro de energía y libros de texto, en que el procedimiento puede proteger las fuentes de aprovisionamiento cuando la oferta del mercado es limitada. El empleo de la negociación competitiva o de la contratación con un solo proveedor tal vez resulte adecuado para contratar con arreglo a un acuerdo marco cerrado en situaciones de urgencia. En la práctica se ha empleado con éxito el procedimiento del acuerdo marco

en combinación con el de solicitud de propuestas con diálogo en contrataciones complejas relativas a equipo de satélites y aparatos de comunicaciones especializados para los organismos policiales.

2. Tal vez sea necesario explicar las posibilidades de apartarse de algún procedimiento previsto en el método elegido para contratar con arreglo a un acuerdo marco, en atención a las peculiaridades del procedimiento del acuerdo marco. Esas posibilidades variarán de un caso a otro, según la clase de acuerdo marco cerrado que se vaya a concertar (por ejemplo, un acuerdo con o sin segunda etapa competitiva, o un acuerdo concertado con uno o varios proveedores o contratistas). En consecuencia, podrá darse una lista ilustrativa y no exhaustiva de esas posibilidades.

3. En el contexto de un acuerdo marco cerrado concertado con varios proveedores, debe impartirse orientación a la entidad adjudicadora para determinar la conveniencia de establecer o no un número mínimo o máximo de proveedores o contratistas que pasaran a ser parte en el acuerdo, o las dos clases de límites, y, en caso afirmativo, qué aspectos tener en cuenta. Por ejemplo, puede necesitarse un número mínimo para garantizar el suministro; cuando se prevé una segunda etapa competitiva debe haber suficientes proveedores o contratistas como para que exista una competitividad efectiva. Cabe establecer un número máximo, por ejemplo, si la entidad adjudicadora considera que habrá más proveedores o contratistas idóneos que presenten ofertas conformes de los que puedan admitirse. Esa situación puede ser fiel reflejo de la capacidad administrativa de la entidad adjudicadora para gestionar la contratación, dado que un número elevado de participantes puede restar eficiencia administrativa al procedimiento. Otra razón para limitar el número de concursantes puede ser la de dar a cada uno de ellos una oportunidad realista de que se le adjudique un contrato con arreglo al acuerdo marco y, de esa forma, alentarlos a que ofrezca el mejor precio y la mejor calidad posibles. Deberán regularse las situaciones en que no se alcance el límite mínimo establecido exigiendo a la entidad adjudicadora que consigne en el pliego de condiciones las medidas que adoptará en ese caso, que podrían abarcar la cancelación de la contratación o la concertación del acuerdo marco con menos proveedores o contratistas.

4. Puede exigirse la aprobación externa de la contratación con arreglo a un acuerdo marco cerrado; si se utilizan acuerdos entre ministerios y organismos públicos, puede considerarse apropiado establecer mecanismos de aprobación previa. De ser así, el reglamento de la contratación pública debe exigir esa aprobación y prever el mecanismo correspondiente. Otra posibilidad es que el Estado promulgante incorpore el requisito de aprobación previa en el propio régimen de la contratación pública y pida que en el reglamento se detalle su mecanismo de funcionamiento.

5. Debe impartirse orientación a la entidad adjudicadora con respecto a la necesidad de concertar acuerdos por separado, en algunos casos, con distintos proveedores o contratistas que sean parte en el acuerdo marco. Debe establecerse la regla supletoria de que cada proveedor o contratista estará sujeto a las mismas condiciones del acuerdo marco. Las excepciones a esa regla se limitan a variaciones de las condiciones de poca entidad que conciernen únicamente a las disposiciones que hayan justificado la celebración de los acuerdos por separado. En el reglamento se deberían dar ejemplos de posibles justificaciones para concertar esa clase de acuerdos, entre ellos la necesidad de proteger derechos inmateriales o de propiedad

intelectual, o de tener en cuenta distintas condiciones en materia de licencias, o el caso de proveedores o contratistas que hayan presentado ofertas correspondientes solo a una parte del contrato. El reglamento debe exigir que se consignen por escrito las razones para concertar acuerdos por separado y las modificaciones que se hayan introducido en cada uno de esos acuerdos.

Duración del acuerdo

6. El reglamento de la contratación pública debe establecer la duración máxima del acuerdo marco cerrado. La experiencia práctica en los países que utilizan esa clase de acuerdos indica que las ventajas potenciales de ese método suelen apreciarse cuando su duración es suficiente como para que se pueda realizar una serie de adquisiciones durante un período de tres a cinco años. Si pasa más tiempo, la competitividad puede verse socavada y es posible que las condiciones del acuerdo ya no reflejen las condiciones reales del mercado.

7. Debe explicarse que cabría variar la duración de los acuerdos, dentro del margen establecido, según las circunstancias de la contratación, es decir, teniendo en cuenta, en particular, los productos que fueran objeto de esta, el mercado de que se tratara y las necesidades de la entidad adjudicadora. Habida cuenta de que algunos mercados pueden evolucionar más rápidamente -en especial aquellos en que suele haber adelantos tecnológicos, como los de tecnología de la información y las telecomunicaciones- o de que las necesidades de la entidad adjudicadora pueden no seguir siendo las mismas a lo largo de un período prolongado, el plazo conveniente para cada contrato tal vez sea mucho más breve que el plazo máximo establecido en el reglamento de la contratación pública. En el caso de algunos productos muy cambiantes, el período apropiado puede medirse en meses. Si se trata de productos, mercados y necesidades estables, el acuerdo marco puede ser de larga duración con objeto de posibilitar una serie de adquisiciones y, de esa forma, obtener los mayores beneficios posibles de esa técnica.

8. En consecuencia, debería impartirse orientación a la entidad adjudicadora para que pudiera determinar la duración máxima de un acuerdo marco en particular dentro del plazo máximo establecido en el reglamento o, de lo contrario, deberían establecerse en el propio reglamento diferentes plazos máximos en relación con las diversas clases de contratos. La orientación también debería abarcar toda limitación externa de la duración de los acuerdos marco (como los requisitos presupuestarios del Estado).

9. Además, debe explicarse que la duración máxima establecida por la entidad adjudicadora para un acuerdo marco en particular dentro del plazo máximo establecido en el reglamento comprende toda posible prórroga del plazo del acuerdo establecido inicialmente. Toda suspensión de la vigencia de un acuerdo marco a que diera lugar un procedimiento de recurso prorrogaría el acuerdo durante el período de suspensión, pero la duración global de este no cambiaría.

10. El reglamento debe prever los casos en que los Estados promulgantes deseen prorrogar los acuerdos marco en circunstancias excepcionales y debe circunscribir esas circunstancias y garantizar que esas prórrogas sean breves y de alcance limitado. Por ejemplo, tal vez no se justifique proceder a una nueva contratación en casos de desastre natural o de restricción de las fuentes de abastecimiento, si el público puede beneficiarse de las condiciones del acuerdo marco en vigor.

11. El reglamento debe establecer controles internos a fin de evitar abusos en lo que concierne a la concesión de prórrogas y excepciones con respecto al plazo establecido inicialmente, en particular si se trata de adjudicar un contrato prolongado o importante cuando está por vencer el plazo del acuerdo marco.

Estimaciones

12. El reglamento de la contratación pública debería impartir orientación a la entidad adjudicadora para decidir si el precio del contrato debe establecerse o no en la primera etapa. Por ejemplo, si el objeto del contrato adjudicable está expuesto a fluctuaciones cambiarias o de precios, o si puede variar la combinación de proveedores de servicios, puede resultar contraproducente tratar de fijar el precio del contrato desde el principio. Una de las críticas que se suelen hacer a los acuerdos marco cerrados es que en esos casos existe la tendencia de fijar los precios a tarifas horarias en general relativamente elevadas. Por el contrario, debería recomendarse que, cuando procediera, el precio del contrato se fijara por tareas o proyectos.

13. Las condiciones del acuerdo marco pueden limitar la flexibilidad comercial si en ellas se garantiza la adquisición de unas cantidades mínimas, o si el acuerdo marco funciona como acuerdo de adquisición exclusivo, aunque esa flexibilidad debería ponderarse teniendo en cuenta los mejores precios ofrecidos por los proveedores o contratistas. En consecuencia, el reglamento debe exigir que: a) en el pliego de condiciones se mencionen cantidades estimadas (no preceptivas), de manera que el acuerdo marco pueda facilitar ofertas realistas basadas en una clara comprensión del alcance de las necesidades de la entidad adjudicadora y que esta pueda adquirir productos al margen del acuerdo marco si varían las condiciones, y b) se mencionen cantidades preceptivas mínimas o máximas. Puede haber mercados en los que una solución parezca mejor que la otra; al respecto, el mecanismo de vigilancia puede impartir orientación o puede dar ejemplos prácticos en los que la entidad adjudicadora ha de elegir entre una y otra opción.

14. Debe explicarse que, si se conocen los valores máximos o mínimos globales que se aplicarán en el acuerdo marco, estos deberían figurar en el propio acuerdo; de lo contrario, se establecerá una estimación. Otra posibilidad es que, si el acuerdo marco va a ser utilizado por varias entidades adjudicadoras, cada una de ellas establezca diferentes valores máximos en función de la naturaleza o del carácter potencialmente obsoleto de los bienes que se vayan a adquirir; en esos casos, deberán figurar los valores correspondientes a cada entidad adjudicadora. Los valores máximos o los valores anuales podrán limitarse mediante procedimientos presupuestarios en los distintos Estados; al respecto, el reglamento debería establecer otras fuentes de reglamentación.

15. Debe exigirse que en el acuerdo marco se consignent todas las estimaciones que se conozcan, así como las limitaciones impuestas a estas, o que se formule una declaración en el sentido de que no es posible proporcionar estimaciones precisas (por ejemplo, cuando se trate de una contratación de emergencia). Facilitar las estimaciones más exactas de que se disponga, cuando no es posible contraer compromisos firmes, promoverá la participación.

Modificaciones permitidas durante la vigencia del acuerdo marco

16. En el contexto del inciso 59.1 d) iii) y del artículo 63 **[**hiperenlaces**]**, el reglamento debe prohibir que en el acuerdo marco se prevea un margen tan amplio de modificaciones que se permitiría introducir en los criterios de evaluación y su ponderación relativa como para invalidar, en la práctica, las salvaguardias previstas en el artículo 63 de la Ley Modelo. Esas salvaguardias restringen el margen permitido de modificaciones de las condiciones de la contratación durante la vigencia del acuerdo marco con objeto de garantizar que no se modifique la descripción del objeto de la contratación y que las demás modificaciones se realicen en forma transparente y previsible.

17. En el reglamento deberían establecerse mecanismos para vigilar la aplicación de esas salvaguardias. La flexibilidad para modificar los criterios de evaluación y su ponderación relativa dentro de los parámetros y márgenes establecidos en el acuerdo marco no debería utilizarse como excusa para no planificar debidamente la contratación, ni debería distorsionar las decisiones de adjudicación para facilitar la tarea administrativa, ni promover la utilización de mandatos amplios que no estuviesen basados en una determinación cuidadosa de las necesidades, ni facilitar irregularidades en la contratación para favorecer a determinados proveedores o contratistas. Estas últimas observaciones pueden adquirir aún más importancia si se subcontrata a un organismo de adquisiciones centralizadas que cobre comisión y que podría utilizar los acuerdos marco para generar ingresos. Los procesos de supervisión pueden contribuir a evitar que los criterios de evaluación relativamente flexibles utilizados en los acuerdos marco oculten otros criterios inapropiados basados en acuerdos o vínculos entre las entidades adjudicadoras y los proveedores o contratistas, así como a descubrir abusos en lo que respecta a predeterminar los resultados de la segunda etapa competitiva que invalidarían la competencia en la primera etapa. En el caso de compras reiteradas, esos riesgos aumentan. La transparencia con que se aplique el margen de flexibilidad y la utilización de un margen determinado y comunicado previamente facilitan esa supervisión.

Funcionamiento y vigilancia del acuerdo marco cerrado

18. Debería explicarse que en el acuerdo marco la base para la adjudicación del contrato (la oferta de menor precio o más ventajosa) por lo general, aunque no necesariamente, será la misma que la de la primera etapa. Por ejemplo, la entidad adjudicadora puede decidir que, entre los proveedores o contratistas que hayan obtenido la mejor puntuación en la primera etapa (escogidos teniendo en cuenta la oferta más ventajosa), sea apropiada la oferta conforme de menor precio que reúna las condiciones exactas de la invitación a participar en la segunda etapa. Si se prevén variaciones y diferentes opciones, el reglamento debe exigir que todas ellas se consignent en el acuerdo marco.

19. Debería hacerse hincapié en las ventajas que ofrecen los procedimientos informatizados de gestión de los acuerdos marco cerrados para lograr una mayor eficiencia y transparencia (por ejemplo, las condiciones pueden publicarse utilizando un hiperenlace, en tanto que una invitación en papel a participar en la segunda etapa competitiva puede ser engorrosa). Debería exigirse que la entidad adjudicadora consignara en el acuerdo marco toda la información especialmente relacionada con la gestión en línea de este, entre otras cosas los requisitos para

conectarse al sitio web, los programas informáticos y las características técnicas especiales y, si procede, la capacidad especial.

20. En el reglamento debería explicarse la manera de obtener los máximos beneficios y de evitar los peligros latentes de los acuerdos marco. En particular, habría que abordar los problemas que han surgido en la práctica en muchos países al utilizar acuerdos marco cerrados, a saber, que los precios tienden a mantenerse fijos, en lugar de variar con el mercado, y que las entidades adjudicadoras, para evitar tener que iniciar un nuevo procedimiento de contratación, tienden a contratar mediante un acuerdo marco existente, aun cuando las condiciones de este no atiendan del todo a sus necesidades o no reflejen las condiciones imperantes en el mercado. Así pues, esas entidades tal vez no prestan suficiente atención al precio ni a la calidad al expedir una orden de compra. Pueden centrarse excesivamente en las especificaciones, en lugar de fijarse en el precio.

21. A fin de hacer frente a esos problemas, el reglamento debería exigir que las entidades adjudicadoras determinaran con regularidad, durante la vigencia de un acuerdo marco cerrado, si este sigue resultando rentable y sigue dando acceso a la mejor oferta que el mercado pueda ofrecer en esos momentos (por ejemplo, si sus precios y condiciones siguen estando actualizados y siguen siendo competitivos). También se debería tener en cuenta la totalidad de las compras previstas con arreglo al acuerdo marco para determinar si los beneficios son mayores que los costos. Dos formas de determinar si la solución técnica o el producto propuesto sigue siendo el mejor que ofrece el mercado son la investigación del mercado y la publicación del alcance del acuerdo marco. Si el acuerdo ha dejado de ofrecer condiciones comerciales ventajosas para la entidad adjudicadora, esta debería emprender un nuevo proceso de contratación (ya sea aplicando uno de los métodos clásicos o mediante un nuevo procedimiento de acuerdo marco). Debería desaconsejarse expresamente la adjudicación de un contrato prolongado o importante hacia el final de la validez del acuerdo marco, ya que eso aumenta el riesgo de adquirir productos obsoletos o a precios exorbitantes.

22. En acuerdos marco celebrados con varios proveedores, cada uno de ellos deseará conocer el alcance de sus obligaciones al principio, y después periódicamente durante la vigencia del acuerdo (por ejemplo, después de efectuarse una compra con arreglo al acuerdo marco). Por consiguiente, el reglamento debería exigir que las entidades adjudicadoras informaran a los proveedores o contratistas periódicamente, o a solicitud de estos, acerca del alcance de sus obligaciones.

Establecimiento de un acuerdo marco abierto y requisitos para concertarlo (artículos 60 y 61 [hiperenlaces**])**

1. En el reglamento se puede recomendar que la invitación a ser parte en un acuerdo marco abierto se ponga permanentemente a disposición de los interesados en el sitio web en el que se gestione el acuerdo. También podría exigirse que toda la información relativa a la gestión de este se ofreciera de continuo en el sitio web. Pueden enumerarse los datos mínimos que deberían figurar, entre ellos, los siguientes:

a) El nombre y la dirección de todas las entidades adjudicadoras que puedan utilizar el acuerdo marco (si este admite que haya varios posibles adquirentes en la segunda etapa);

b) El organismo que se encargará de establecer y gestionar el acuerdo marco, si hay más de un adquirente;

c) Las prerrogativas del organismo de adquisiciones centralizadas, si lo hubiera (por ejemplo, si está autorizado a emprender las contrataciones previstas en su propio nombre (como adquirente principal), sin que sea necesario, por ende, publicar detalles de las entidades que son sus propios clientes; sin embargo, si el organismo actúa como representante, esos detalles deben darse a conocer);

d) Un número máximo de proveedores o contratistas que puedan ser parte en el acuerdo marco, si lo hubiera, y los procedimientos y criterios para escoger ese número máximo de partes. En el reglamento debe hacerse hincapié en que establecerlo puede justificarse debido a limitaciones de capacidad del sistema de comunicaciones, no por otro motivo. Deben precisarse las técnicas que puede utilizar la entidad adjudicadora para escoger ese número máximo de partes sin hacer discriminación, por ejemplo, por orden de presentación de las ofertas, por sorteo, por rotación, o al azar en un mercado de productos básicos, y para alertar a los proveedores o contratistas acerca de la posibilidad de que se impugne su decisión;

e) La duración del acuerdo marco. En este contexto, el reglamento puede exigir que la duración de un acuerdo marco abierto no sea excesiva y que se determine teniendo en cuenta el carácter del objeto de la contratación a fin de admitir nuevas soluciones y nueva tecnología y evitar la obsolescencia. Además, los proveedores o contratistas pueden mostrarse renuentes a participar en un acuerdo de duración ilimitada;

f) Los requisitos que deben reunir los proveedores o contratistas para ser parte en el acuerdo;

g) Todas las demás condiciones del acuerdo marco;

h) La lista de proveedores o contratistas que son parte en el acuerdo marco (en el reglamento puede explicarse que publicar así la lista podría constituir el cumplimiento efectivo del requisito de anunciar públicamente la concertación del acuerdo marco, previsto en el artículo 23.1 de la Ley Modelo);

i) Los nombres de los proveedores o contratistas a quienes se adjudicaron contratos con arreglo al acuerdo marco y los precios de los contratos adjudicados (en el reglamento puede explicarse que publicar esa información podría constituir el cumplimiento efectivo del requisito de anunciar públicamente los contratos adjudicados con arreglo al acuerdo marco, previsto en el artículo 23 de la Ley Modelo [\[**hiperenlace**\]](#));

j) Los anuncios y todas las condiciones de la segunda etapa competitiva;

k) La copia de la invitación a participar en la segunda etapa competitiva.

2. En el contexto del párrafo 5 del artículo 60, en el reglamento debe hacerse hincapié en la importancia que reviste examinar rápidamente las solicitudes para pasar a ser parte en el acuerdo marco abierto. Al gestionar un acuerdo marco abierto debe evaluarse cuidadosamente la interacción entre los plazos para presentar las propuestas definitivas, el tiempo necesario para evaluar las propuestas indicativas y la frecuencia y magnitud de la segunda etapa competitiva. Debe destacarse la utilidad de llevar a cabo esas segundas etapas con relativa frecuencia y de que estas

sean de una magnitud razonable para aprovechar las ventajas que puede ofrecer un mercado competitivo y dinámico.

Artículo 62. Segunda etapa de un procedimiento para la adjudicación de contratos con arreglo a un acuerdo marco [\[hiperenlace**\]](#)**

1. En el reglamento de la contratación pública se debe explicar la manera en que funcionará en la práctica la opción de invitar a la segunda etapa competitiva únicamente a las partes en el acuerdo marco que en ese momento puedan presentar una oferta que responda a las necesidades pertinentes de la entidad adjudicadora en relación con el objeto de la contratación, sin por eso vulnerar los principios de transparencia y de trato justo y equitativo de los proveedores o contratistas. Debe hacerse hincapié en que el propósito de la disposición es aumentar la eficiencia, no restringir la competitividad. Debe establecerse la presunción de que todos los proveedores o contratistas que sean parte en el acuerdo pueden responder a las necesidades de la entidad adjudicadora en relación con el objeto de la contratación, a menos que en el acuerdo marco o en sus propuestas iniciales o indicativas se prevea lo contrario. En consecuencia, el reglamento debería exigir que la entidad adjudicadora interpretara la frase “que, en ese momento, puedan presentar una oferta que responda a las necesidades” en un sentido muy estricto, a la luz de las condiciones del acuerdo marco y de las propuestas iniciales o indicativas. Pueden darse ejemplos en los que quede justificado invitar a un grupo limitado de proveedores o contratistas que en ese momento puedan presentar una oferta que responda a las necesidades de la entidad adjudicadora en relación con el objeto de la contratación. Por ejemplo, el acuerdo marco puede autorizar a los proveedores o contratistas a que entreguen hasta determinadas cantidades (en cada segunda etapa competitiva o en general), o en las propuestas iniciales o indicativas puede establecerse que determinados proveedores o contratistas no pueden cumplir ciertas exigencias de combinaciones especiales o ciertos requisitos de calidad.

2. La salvaguardia importante contra el abuso o el uso erróneo de esa opción, por ejemplo, si se recurre a ella para favorecer a determinados proveedores o contratistas en detrimento de otros, es la exigencia de que la entidad adjudicadora dé aviso de la segunda etapa competitiva a todas las partes en el acuerdo marco simultáneamente al enviar la invitación a participar en ella. Esa clase de aviso hará posible que todo proveedor o contratista excluido impugne la decisión de la entidad adjudicadora de no invitarlo. El reglamento puede establecer el período mínimo que ha de transcurrir tras el aviso para que pueda comenzar la segunda etapa.

3. En el reglamento deben destacarse las consecuencias desfavorables de que se ponga en tela de juicio la eficiencia que se procura lograr con los procedimientos de acuerdo marco: las excepciones a la regla supletoria de invitar a todos los proveedores o contratistas a la segunda etapa competitiva deben considerarse con cuidado y deben aplicarse cuando se vean verdaderamente justificadas, con objeto de evitar que la entidad adjudicadora tenga que enfrentarse a muchos proveedores o contratistas agraviados que impugnen la evaluación que haya hecho de su capacidad para responder a sus necesidades en un momento dado. El reglamento debe exigir que en el expediente del proceso de contratación la entidad adjudicadora explique las razones para excluir de la segunda etapa competitiva a alguna de las partes en el acuerdo.

4. El reglamento debería prever la manera de invitar a la segunda etapa competitiva y de dar aviso de ella, por ejemplo, que tanto la invitación como el aviso deben efectuarse por escrito y ser expedidos simultáneamente y en forma automática por el sistema a cada uno de los proveedores o contratistas de que se trate. Si bien no hay un requisito que obligue a publicar una notificación general de la segunda etapa competitiva, publicar un aviso en la página de dominio público del sitio web en que se gestiona el acuerdo marco daría ese resultado, y el reglamento puede exigir a las entidades adjudicadoras que así lo hagan.

5. En el apartado 4 b) se dispone el contenido de la invitación a la segunda etapa competitiva. El reglamento debe precisar todo otro requisito relacionado con la preparación y presentación de las propuestas y los demás aspectos de la segunda etapa competitiva que no se enumeran en el apartado 4 b) del artículo y que la entidad adjudicadora debe consignar en la invitación a presentar propuestas en la segunda etapa competitiva. Si esos requisitos figuraran en otras normas aplicables del Estado promulgante, el reglamento debería remitirse a ellas. También debe aclararse si los proveedores o contratistas pueden modificar en la segunda etapa las propuestas presentadas en la primera (sus propuestas iniciales) de una manera que resulte menos favorable para la entidad adjudicadora (por ejemplo, aumentando los precios si varían las condiciones del mercado).

6. Como se indicó anteriormente en el contexto de los acuerdos marco cerrados, en el reglamento ha de explicarse el funcionamiento del margen permitido de perfeccionamiento de las condiciones de la contratación en la segunda etapa competitiva, entre otras cosas, la ponderación relativa de los criterios y subcriterios de evaluación. La flexibilidad para proceder a ese perfeccionamiento está limitada por la aplicación del artículo 63 [\[**hiperenlace**\]](#), según el cual no está permitido modificar la descripción del objeto de la contratación y solo podrán introducirse otros cambios en la medida en que lo permita el acuerdo marco. La necesidad de introducir cambios en los productos o de efectuar modificaciones de carácter técnico debería estar mencionada en el propio acuerdo marco, en el que también deberían expresarse las necesidades de la contratación de una manera suficientemente flexible y funcional (con arreglo a los parámetros del artículo 10 [\[**hiperenlace**\]](#)) como para admitir esas modificaciones. Otras condiciones que pueden perfeccionarse son, por ejemplo, las combinaciones de componentes (en el contexto de la descripción general), las garantías y los plazos de entrega. La orientación proporcionada a las entidades adjudicadoras en relación con ese aspecto de los acuerdos marco debería basarse en la necesidad de conciliar la flexibilidad necesaria para establecer una relación óptima entre calidad y precio con la necesidad de que exista suficiente transparencia y de que se impongan limitaciones a efectos de prevenir abusos.

7. En relación con el inciso 4 b) iv), en el reglamento debe destacarse la importancia de establecer un plazo adecuado para la presentación de las propuestas con objeto de preservar la eficiencia sin menoscabar los intereses legítimos de los proveedores o contratistas que sean parte en el acuerdo marco. Por ejemplo, en los acuerdos marco abiertos el plazo puede expresarse en horas, en un día, o un período análogo. De lo contrario, quedaría comprometida la eficiencia administrativa del procedimiento y las entidades adjudicadoras no podrían aprovechar las ventajas que ofrece esa técnica. El período que transcurra entre la publicación de la invitación a presentar propuestas para la segunda etapa

competitiva y la fecha límite estipulada para su presentación deberá determinarse teniendo en cuenta el plazo que se considere suficiente para preparar las propuestas en las circunstancias del caso (cuanto más sencillo sea el objeto de la contratación, más breve será la duración posible). Otra consideración que ha de tenerse en cuenta es la manera de prever un plazo mínimo suficiente como para que se puedan impugnar las condiciones de la convocatoria. Puede explicarse que el requisito temporal estará supeditado en todo momento a las necesidades razonables de la entidad adjudicadora, como se dispone expresamente en el artículo 14.2 de la Ley Modelo, necesidades estas que, en ciertas circunstancias, pueden prevalecer sobre toda otra consideración, por ejemplo, en casos de extrema urgencia tras producirse una catástrofe.

8. Debe explicarse la aplicación de una moratoria en el contexto de las diversas clases de acuerdos marco y observarse que se justificará que esta tenga una duración menor en el contexto de un acuerdo marco abierto, ya que en esos casos por lo general se adquieren productos estándar sencillos. Deberían explicarse las razones para no exigir que se decretara una moratoria en el contexto de un contrato adjudicado con arreglo a un acuerdo marco cerrado sin segunda etapa competitiva.

Artículo 63. Modificaciones durante la vigencia del acuerdo marco

[hiperenlace**]**

Como se indicó anteriormente en el contexto de los acuerdos marco cerrados y del artículo 62, en el reglamento deben explicarse los límites impuestos a la posibilidad de introducir modificaciones en las condiciones de la contratación durante la vigencia de un acuerdo marco. También deberían explicarse las circunstancias en que sería apropiado formular la descripción del objeto de la contratación de manera funcional o basándose en el producto, mencionando un número mínimo de requisitos técnicos, cuando procediera, con miras a poder modificar posteriormente el objeto de la contratación o los aspectos técnicos. La conveniencia de aplicar ese criterio dependerá del carácter de la propia contratación. El riesgo de que se cometan abusos existe de todas formas, es decir, tanto si se permite consignar especificaciones genéricas amplias como si se permite introducir modificaciones; por motivos de eficiencia administrativa, el acuerdo marco puede seguir empleándose más de lo previsto, lo que puede dar lugar a adjudicaciones poco transparentes y poco competitivas. Por otra parte, esa falta de transparencia y de competitividad también puede comprometer considerablemente la rentabilidad de los contratos adjudicados. Por consiguiente, en el reglamento deberían preverse esos riesgos en forma bastante detallada y disponerse medidas apropiadas para mitigarlos.

X. Temas que deberán tratarse en el reglamento de la contratación pública en el contexto del Capítulo VIII de la Ley Modelo (Procedimientos de recurso) [\[hiperenlace**\]](#), expuestos en el orden de los artículos correspondientes**

Observaciones generales

1. Está previsto que las disposiciones de este capítulo se complementen con reglamentos y normas de procedimiento detalladas que garanticen la eficacia, rapidez y economía de los mecanismos de recurso. Dependiendo de la tradición jurídica del Estado promulgante, esas disposiciones complementarias se incluirán en el reglamento de la contratación pública o en las reglamentaciones aplicables de otras ramas del derecho.
2. Asimismo, hay otras ramas del derecho y otros organismos del Estado promulgante que pueden influir en el mecanismo de recurso previsto en el capítulo VIII, por ejemplo, si un recurso se basa en denuncias de fraude o corrupción, o de quebrantamiento del régimen de la libre competencia. En consecuencia, el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables deberían exigir que se diera a conocer públicamente la información relativa a esa clase de denuncias, a efectos de poner sobre aviso a las autoridades competentes para que pudieran adoptar medidas apropiadas.
3. En esos instrumentos deben analizarse todas las cuestiones que pueden influir en la posibilidad de conciliar debidamente los intereses de los proveedores o contratistas con las necesidades de la entidad adjudicadora, entre ellas el grupo de personas que tengan derecho a impugnar los actos o las decisiones de la entidad adjudicadora (como se indica más adelante, en relación con el artículo 64) y las consideraciones relativas a las circunstancias en las que esa suspensión puede o no ser conveniente y en que debería levantarse la prohibición prevista en el artículo 65, como en el caso de desastres naturales, situaciones de emergencia y situaciones en que de otra forma se pudiera causar un daño desproporcionado a la entidad adjudicadora o a algún otro interesado. En ese contexto, en el reglamento de la contratación pública debe explicarse con detalle la interacción de todos los límites cronológicos pertinentes en relación con los procedimientos de recurso (entre otras cosas, la duración de la moratoria, la expiración del plazo de presentación, el período al cabo del cual caducará la prohibición prevista en el artículo 65, la duración de la suspensión y los plazos para adoptar decisiones al respecto y para las notificaciones).
4. En el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables debería recomendarse que no se entablaran recursos paralelos y establecerse una secuencia clara de las solicitudes que puedan presentarse a las instancias administrativas y judiciales de revisión del Estado promulgante. Si se desea, pueden incluirse disposiciones relativas a la secuencia de las solicitudes, la que puede depender de las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados promulgantes. Algunos Estados son más flexibles y no exigen que el proveedor o contratista agote todas las posibilidades que le ofrece el mecanismo de recurso ante la entidad adjudicadora para poder recurrir ante el órgano independiente o el tribunal. De modo análogo, puede permitirse al proveedor o contratista agraviado

que no esté satisfecho con la decisión adoptada por la entidad adjudicadora en relación con el recurso interpuesto que apele contra esa decisión ante el órgano independiente o el tribunal. Si la solicitud se presentó directamente al órgano independiente, el recurso de apelación contra su decisión puede entablarse ante cualquier autoridad competente dentro de ese órgano, de existir esa opción, o ante el tribunal. No obstante, algunos Estados pueden exigir que se agoten todas las medidas, o algunas de ellas, antes de dirigirse al tribunal. El reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables pueden exigir que el proveedor o contratista que se sienta perjudicado primero presente una solicitud de reconsideración a la entidad adjudicadora y, después, en caso de apelar contra una decisión relativa a ese recurso, lo haga ante la estructura del órgano independiente, antes de recurrir ante el tribunal. Otra posibilidad es que se permita pasar por alto a la entidad adjudicadora, pero se exija agotar todos los recursos de que se disponga dentro de la estructura del órgano independiente antes de recurrir ante el tribunal. Al respecto, el reglamento de la contratación pública debe respetar las obligaciones internacionales del Estado promulgante, entre ellas las emanadas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Nueva York, 31 de octubre de 2003)³² y del Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública, que pueden exigirle que garantice la posibilidad de apelar efectivamente ante un órgano independiente y que se pueda proceder a la revisión judicial de las decisiones de todo órgano de revisión que no sea un tribunal.

Artículo 64. Derecho de recurso y apelación **[hiperenlace**]****

1. El reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables deben impartir o exigir que se imparta orientación detallada sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 64 en consonancia con el ordenamiento jurídico y la estructura administrativa del Estado promulgante. En particular, deben precisar el grupo de personas que tienen derecho a recurrir contra cualquier acto o decisión de la entidad adjudicadora en el curso del proceso de contratación de que se trate. A diferencia de otros regímenes, la Ley Modelo otorga ese derecho únicamente a los proveedores y contratistas (esta expresión abarca a los proveedores o contratistas potenciales previstos en la definición del artículo 2 **[**hiperenlace**]**, por ejemplo, los que hayan sido excluidos en la etapa de precalificación o de preselección), y no al público en general ni a los subcontratistas. Eso se debe a que ese derecho nace a raíz de una alegación del proveedor o contratista de que ha sufrido una pérdida o un daño de resultados del incumplimiento de la ley sobre la contratación pública por parte de la entidad adjudicadora. Esas limitaciones tienen por objeto garantizar que los recursos guarden relación con los actos o decisiones de la entidad adjudicadora en un determinado proceso de contratación y evitar que este se vea menoscabado excesivamente por recursos basados en cuestiones políticas o especulativas, o en transgresiones nominales, y también reflejan el hecho de que el mecanismo de recurso no es el único método de supervisión de que se dispone.

³² Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 2349. La Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 58/4. De conformidad con el artículo 68.1 de la Convención, esta entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. El texto de la Convención puede consultarse también en www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf (consultado en mayo de 2013).

2. En el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables también debe tenerse en cuenta la posibilidad de que un proveedor o contratista interponga un recurso, o la competencia de diversos organismos públicos para conocer del recurso, invocando otras normas aplicables del derecho interno del Estado promulgante, entre ellas las que establecen los requisitos que debe cumplir un proveedor o contratista para interponer un recurso u obtener reparación.
3. Todo recurso interpuesto ante el tribunal -por lo general denominado revisión judicial- queda al margen del régimen del reglamento de la contratación pública, pero tiene consecuencias para este. En consecuencia, sería conveniente que el reglamento u otras reglamentaciones aplicables se remitieran a otras normas jurídicas aplicables del Estado promulgante que establecieran la autoridad competente y las actuaciones judiciales pertinentes, de manera que tanto las entidades adjudicadoras como los proveedores y contratistas tuvieran un panorama completo de los recursos de que disponen. Eso se aplica, en particular, al mecanismo de apelación, que en la Ley Modelo únicamente está previsto por la vía judicial y con arreglo a la ley del foro competente. El reglamento u otras reglamentaciones aplicables deben disponer que se oriente a los usuarios del régimen de la contratación pública en cuanto a la posibilidad de que ese mecanismo se aplique por la vía judicial o en alguna otra instancia en los Estados promulgantes y a la manera en que funciona.

Artículo 65. Efectos de un recurso [\[hiperenlace**\]](#)**

1. En el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables debería explicarse a las entidades adjudicadoras el alcance de la prohibición prevista en el artículo, en particular las diferencias entre esa prohibición y la suspensión que puede aplicar la entidad adjudicadora u ordenar un órgano independiente, un tribunal u otra autoridad competente. Si bien el artículo prohíbe la entrada en vigor de un contrato en vías de adjudicación hasta que se haya dirimido el recurso o la apelación, también puede ser necesario suspender el proceso de contratación. La suspensión del proceso es una medida de mayor alcance que la prohibición prevista en el artículo, dado que paraliza todo el procedimiento.
2. En alguno de esos instrumentos debería explicarse lo que se entiende por “ninguna medida que dé vigencia a un contrato en vías de adjudicación o a un acuerdo marco en vías de negociación” y que la prohibición no es absoluta (pueden invocarse razones de interés público urgente para levantarla). Toda “medida que dé vigencia a un contrato en vías de adjudicación o a un acuerdo marco en vías de negociación” abarcaría, por ejemplo, despachar una notificación de aceptación al proveedor o contratista ganador o, si eso se previera, toda medida encaminada a firmar un contrato escrito o a recibir la aprobación de otro organismo para que entrara en vigor el contrato adjudicable (o el acuerdo marco).
3. También debe explicarse la expresión “participantes en las actuaciones del recurso interpuesto” por oposición a los “participantes en el proceso de contratación”. La primera expresión abarca, en primer lugar, a la entidad adjudicadora y al o los proveedores o contratistas que hayan entablado el recurso (y, de ser pertinente, a toda autoridad pública cuyos intereses se vieran o pudieran verse afectados por la solicitud, por ejemplo, la autoridad que dé la aprobación). Por lo general se trata de un grupo más restringido que el de los participantes en el proceso de contratación, si bien, en virtud del derecho que confiere el artículo 68

[**hiperenlace**], puede haber más proveedores o contratistas que intenten sumarse a las partes litigantes, o entablar su propio recurso, si alegan haber sufrido una pérdida o un daño de resultados de las mismas circunstancias. En ese contexto, los “participantes en las actuaciones” pueden formar un grupo variado, lo que depende del momento en que se entable el recurso y del objeto de este. Todo proveedor o contratista que participe en el proceso de contratación con el que se relacione el recurso puede tomar parte en el ejercicio del recurso. También pueden participar otras autoridades públicas. Al respecto, por “autoridad pública” se entiende toda entidad comprendida en la definición de “entidad adjudicadora” prevista en el artículo 2 [**hiperenlace**], por ejemplo, las entidades que están facultadas para gestionar o utilizar un acuerdo marco, sin perjuicio del requisito previsto en el artículo 68.1 de que sus intereses puedan verse afectados por dicho recurso. Al respecto, cabe observar que la parte en un acuerdo marco cuyos intereses se vean o puedan verse afectados por el recurso será, muy probablemente, la principal entidad adjudicadora, y no otras entidades que hayan pasado a ser parte en el acuerdo marco al comienzo del proceso de contratación. Esa expresión también comprendería a toda autoridad que aprobara el contrato adjudicado en el contexto del proceso de contratación correspondiente (véanse, por ejemplo, los artículos 22.7, 30.2 y 30.5 e) [**hiperenlaces**], en que se regula la función de la autoridad que ha de dar la aprobación).

4. En el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables debe aclararse si un órgano independiente puede adoptar la decisión de levantar la prohibición sin que lo solicite la entidad adjudicadora. Esa opción puede ser apropiada en los Estados en que se utilice un método más indagatorio que contradictorio, pero puede serlo menos en otros.

Artículo 66. Recurso de reconsideración presentado ante la entidad adjudicadora [**hiperenlace**]

1. En el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables pueden figurar disposiciones encaminadas a resolver las controversias con prontitud promoviendo el empleo del otro mecanismo de recurso previsto en este artículo. También puede exhortarse a difundir ampliamente y a explicar al público los beneficios del mecanismo de reconsideración por la entidad adjudicadora y la forma en que funciona para que se pueda utilizar con eficacia. Además, deberían establecerse mecanismos de vigilancia y seguimiento con objeto de observar la respuesta a los recursos presentados y comprobar si estos son tratados debidamente y si se obtienen los beneficios que ofrecen.

2. En alguno de esos instrumentos deben analizarse las diferencias entre la notificación con aclaraciones examinada anteriormente en el contexto del artículo 22 y una solicitud formal de reconsideración presentada ante la entidad adjudicadora. Para evitar confusión, deberían destacarse las principales diferencias entre los dos procedimientos en lo que respecta a los objetivos, las formas de aplicarlos y los posibles resultados.

3. En alguno de los instrumentos también debe hacerse hincapié en que no es posible presentar un recurso de reconsideración a la entidad adjudicadora si el contrato adjudicado ha entrado en vigor; por el contrario, después del período de formación del contrato el recurso estará comprendido en el ámbito de competencia del órgano de revisión independiente o judicial, es decir, el órgano independiente o

el tribunal. Además, debería explicarse que, si se entabla un recurso ante un órgano independiente o un tribunal, cesa la competencia de la entidad adjudicadora con respecto al recurso anterior. No obstante, la entidad adjudicadora puede seguir adelante con la medida correctiva en el proceso de contratación correspondiente, siempre y cuando esa medida no contravenga una orden del órgano independiente o del tribunal, u otras disposiciones de derecho interno. Si el recurso interpuesto ante un órgano independiente o un tribunal es de alcance limitado, sus consecuencias exactas para el recurso anterior presentado a la entidad adjudicadora estarán reguladas por el derecho interno, y el reglamento deberá remitirse debidamente a las normas aplicables.

4. En lo que respecta a los plazos para presentar recursos de reconsideración, en el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables deberían explicarse los siguientes aspectos:

a) Que por “condiciones de la convocatoria, de la precalificación o de la preselección” se entenderá toda cuestión suscitada por el proceso de contratación antes de que venza el plazo para la presentación de solicitudes de precalificación o preselección o de ofertas, por ejemplo, la elección de un método de contratación o de un método de convocatoria cuando exista la opción entre la convocatoria abierta y la directa y la limitación de la participación en el proceso de contratación de conformidad con el artículo 8 [\[**hiperenlace**\]](#). Así pues, quedan excluidas las cuestiones planteadas en el curso de la precalificación o la preselección, previstas en la segunda parte del apartado 2 a) del artículo, o durante el examen y la evaluación de las ofertas, previstas en el apartado 2 b) del artículo;

b) La frase “antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas” en el contexto del apartado 2 a), y puede establecerse el plazo máximo absoluto para presentar recursos, a fin de evitar que se presenten recursos obstructivos (y tal vez caprichosos) justo antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. El objetivo debería ser que los recursos relacionados con las condiciones de la convocatoria, la precalificación o la preselección y con las decisiones adoptadas por la entidad adjudicadora en las etapas de precalificación o preselección se presentaran lo antes posible;

c) Cuándo se consideraría que un recurso no se presentó a tiempo y debe ser desestimado por la entidad adjudicadora. Por ejemplo, cuando se ha decretado una moratoria y se necesita la aprobación de otra autoridad para que entre en vigor el contrato adjudicado (o el acuerdo marco celebrado), un recurso interpuesto tras cumplirse el periodo de la moratoria, pero antes de aprobarse el contrato, estará fuera de plazo; y

d) Que el plazo opcional previsto en el apartado 2 b) es aplicable a todas las situaciones en que no se haya decretado una moratoria (por ejemplo, por haberse invocado una excepción legítima o por razones de ilegalidad).

5. El reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables pueden establecer o exigir que se establezcan las normas procesales que regirían los recursos de reconsideración. En esas normas pueden abordarse los siguientes aspectos:

a) El material probatorio que ha de presentar el solicitante para fundamentar las razones por las que, a su juicio, se justifique la reconsideración o medida

correctiva solicitada. La forma de hacerlo diferirá según el caso, y es necesario conceder flexibilidad al respecto. Sin embargo, la regla supletoria debería ser que la solicitud de reconsideración se presentara acompañada de todo el material probatorio de que se dispusiera; presentarlo más tarde puede frustrar el propósito de exigir a la entidad adjudicadora que la atienda con prontitud;

b) Los plazos para notificar a todos los interesados, así como la manera de hacerlo y los medios necesarios. El objetivo es garantizar que se informe a todos los interesados, entre ellos los participantes en el proceso de contratación (aunque no hayan facilitado sus señas), de que se ha presentado el recurso. En un contexto electrónico, por ejemplo, lo mejor sería publicar ese aviso en el mismo sitio web en que se publicó el del inicio de la contratación; en consecuencia, el reglamento debería alentar o exigir a la entidad adjudicadora que así lo hiciera;

c) El orden en que la entidad adjudicadora habrá de examinar las diversas cuestiones y adoptar decisiones al respecto (por ejemplo, si se presentó el recurso dentro del plazo fijado; si el autor del recurso está legitimado para presentarlo; si se observan errores manifiestos en los fundamentos de hecho o de derecho del recurso o en la comprensión de la reglamentación, o, en los casos en que el recurso carezca de fundamento u obedezca a un capricho, si el carácter del recurso y el momento en que se presentó, así como los hechos y circunstancias de la contratación correspondiente, justifican la suspensión del procedimiento y, de ser así, durante cuánto tiempo, así como las medidas correctivas que deben adoptarse;

d) La forma, el modo y el lugar en que se dejará constancia de todas las decisiones adoptadas por la entidad adjudicadora durante el procedimiento de recurso de reconsideración y su contenido mínimo (por ejemplo, que las decisiones consten por escrito y que se indiquen la o las medidas adoptadas y las razones para hacerlo, lo que no solo coadyuvará a la comprensión del proceso y, de esa forma, a prevenir controversias ulteriores, sino que también facilitará todo recurso administrativo o judicial que se desee presentar posteriormente, y que todo eso forme parte del expediente del proceso de adjudicación). Al respecto, cabe observar que, si bien en algunos regímenes de la contratación el hecho de que la entidad adjudicadora no se pronuncie respecto de un recurso puede interpretarse como desestimación de este, en la Ley Modelo se exige que la desestimación conste por escrito. Por lo tanto, en el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables debe aclararse el efecto de que la entidad adjudicadora no se pronuncie sobre un recurso dentro de los plazos establecidos por la ley para adoptar medidas y decisiones al respecto (lo que abarca las notificaciones previstas en el párrafo 3 del artículo), en particular, que el hecho de que no haya un pronunciamiento o de que no se adopten medidas puede dar lugar a un recurso de revisión ante un tribunal u otra autoridad competente del Estado promulgante;

e) En el contexto del artículo 67.8, la manera en que la entidad adjudicadora facilitará acceso efectivo al órgano independiente a todos los documentos que obren en su poder y que sean pertinentes para el proceso de adjudicación objeto de la revisión, así como los medios para hacerlo, todo lo cual debe cumplir el requisito impuesto por la ley de acceso rápido después de recibir la notificación del recurso. Eso puede resultar más fácil si se utilizan medios informatizados;

f) Los derechos de las personas que se sumen al proceso de reconsideración, entre otros el derecho de presentar una solicitud para que se levante una suspensión decretada;

g) La manera de tratar la información reservada, entre otras cosas en el contexto de la adopción de decisiones y el despacho de notificaciones, así como del acceso al expediente por parte de los litigantes y del órgano independiente. Al respecto, en el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables puede explicarse, en particular, el propósito de las disposiciones que exigen dar aviso del contenido del recurso: eso permite a la entidad adjudicadora evitar que se revele información potencialmente reservada sin tener que expurgar el texto.

6. En el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables deben explicarse los efectos jurídicos de la desestimación del recurso, en particular que esta constituye un pronunciamiento acerca de la solicitud y, como tal, puede ser impugnada; si no lo es, da lugar a que se levante la prohibición de la entrada en vigor del contrato adjudicado o del acuerdo marco tras haber vencido el plazo previsto en el artículo 65 para entablar un recurso o apelar contra la decisión.

7. En alguno de esos instrumentos debe impartirse orientación a las entidades adjudicadoras con respecto a las medidas correctivas que pueden adoptar: por ejemplo, rectificar el curso de la contratación para compatibilizarlo con el régimen legal o reglamentario de la contratación pública o con toda otra norma aplicable; si se ha aceptado una oferta y se demuestra que debería haberse aceptado otra, abstenerse de dar el aviso de aceptación al proveedor o contratista aceptado inicialmente y aceptar, en su lugar, la otra oferta, o cancelar el proceso de contratación y abrir otro.

8. A fin de reducir lo más posible los riesgos de abuso de la facultad discrecional de la entidad adjudicadora con respecto a la imposición de una suspensión, en alguno de esos instrumentos se deben dar ejemplos de circunstancias en que sería necesario imponerla. Otro criterio sería reglamentar el ejercicio de la facultad discrecional de la entidad adjudicadora para decidir acerca de la suspensión del proceso de adjudicación. Esa medida puede ser particularmente apropiada si la entidad adjudicadora carece de experiencia en materia de procedimientos de recurso, si en el proceso de adjudicación en cuestión las decisiones han sido adoptadas por otro organismo, o si se desea promover la resolución rápida de las controversias fomentando la presentación de recursos a la entidad adjudicadora en primer lugar. Si se prefiere ese criterio, en el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables deberían incluirse disposiciones más prescriptivas, teniendo en cuenta la necesidad de conciliar el derecho del proveedor o contratista a que se examine su recurso o apelación con la necesidad de la entidad adjudicadora de concluir un contrato (o acuerdo marco) de una manera económica y eficiente, sin demoras ni perturbaciones indebidas en el proceso de adjudicación.

Artículo 67. Recurso de revisión ante un órgano independiente [\[hiperenlace**\]](#)**

1. En el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables de los Estados promulgantes que deseen establecer un mecanismo de revisión independiente deberá determinarse el órgano adecuado al que se encomendará esa función, ya sea una entidad existente o una nueva entidad creada

con ese fin. Puede ser, por ejemplo, un órgano supervisor de la contratación pública en general o algún otro órgano pertinente cuya competencia se extienda a otros asuntos (por ejemplo, el órgano que ejerza control y supervisión financieros de las operaciones del Estado y de la administración pública en general (aunque el alcance de la revisión no debe limitarse a tal control y supervisión)), o una instancia administrativa especial cuya competencia sea, exclusivamente, resolver las controversias en el ámbito de la contratación pública.

2. Alguno de esos instrumentos debería regular la composición y el funcionamiento de ese órgano; debería destacarse la importancia que revisten la independencia y los conocimientos especializados de las personas que actúen en él. Se debe asignar importancia especial a las pruebas, la confidencialidad y la celebración de audiencias a fin de asegurarse de que todas las partes que intervengan en los procedimientos sean plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones al respecto, garantizar la coordinación de todos los procedimientos y posibilitar una apelación eficaz y eficiente de una decisión de un órgano independiente. Se podría permitir que representantes de la sociedad civil y otros agentes observaran el desarrollo de los procedimientos de recurso y disponer los medios necesarios para hacerlo, en consonancia con la tradición jurídica del Estado promulgante interesado.

3. Se necesitarán normas procesales sólidas para asegurarse de que en las actuaciones las cuestiones controvertidas se examinen con la profundidad necesaria y en su debido momento. El reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables deben establecer o exigir la formulación de normas procesales y directrices relativas al funcionamiento del órgano independiente que abarquen los siguientes aspectos:

a) La forma en que deben presentarse los recursos, entre ellos los que tengan por objeto permitir que el proceso de adjudicación siga su curso debido a consideraciones de interés público urgentes (por ejemplo, si es presentado por la entidad adjudicadora ex parte, o inter partes);

b) Las cuestiones relativas a las pruebas y el examen de estas, entre otras cosas, normas y procedimientos claros en lo que respecta a los elementos y las pruebas que debería presentar la entidad adjudicadora para fundamentar las razones de interés público urgente de su solicitud;

c) La manera de llevar a cabo el proceso de revisión (por ejemplo, si se han de celebrar audiencias públicas);

d) Cuestiones relativas a los observadores;

e) Los medios para que el órgano independiente dé aviso rápidamente a todos los interesados y el modo y lugar de publicación de las notificaciones y los medios para hacerlo, si así lo exige la ley;

f) La facultad de la entidad adjudicadora para hacer averiguaciones si debe adoptar la decisión sobre la suspensión antes de que el órgano independiente haya podido examinar los documentos relativos al proceso de contratación, entre ellos el expediente completo de esta;

g) Los derechos de las entidades cuyos intereses puedan verse afectados por el recurso (entre ellas, otras entidades públicas), lo que abarca intervenir en el procedimiento de recurso o solicitar que se levante una suspensión decretada;

h) Las medidas correctivas que puede ordenar de inmediato el órgano independiente en los casos que den lugar a la suspensión automática del proceso de adjudicación prevista en el párrafo 4 del artículo, entre ellas, ordenar a la entidad adjudicadora que prorrogue el plazo para la presentación de ofertas o que corrija las condiciones de la convocatoria, la precalificación o la preselección;

i) La competencia para conocer de los recursos presentados al órgano independiente fuera de plazo (en el apartado 2 c) del artículo se otorga al órgano independiente la facultad para desestimar el recurso aunque se haya establecido que está motivado por razones de interés público importantes; tampoco se prohíbe al órgano independiente que admita a trámite los recursos presentados fuera de plazo, aun cuando no existan razones de interés público importantes). En las normas se pueden dar ejemplos de circunstancias que pueden justificar la admisión de un recurso habiendo ya expirado la moratoria, por ejemplo, en caso de que se hayan descubierto irregularidades fraudulentas o actos de corrupción;

j) La manera de facilitar el acceso a toda la documentación relativa al proceso de contratación que obre en poder de la entidad adjudicadora (en forma tangible o virtual), previendo, por ejemplo, que los documentos pertinentes se vayan facilitando gradualmente (se podría presentar una lista de todos los documentos al órgano independiente para que este pudiera determinar los documentos relacionados con el procedimiento de contratación pertinente). Se debería tratar de evitar que se trastornaran excesivamente los procesos de contratación y de revisión proporcionando medios seguros y eficientes para transmitir esos documentos y haciendo notar la conveniencia de utilizar instrumentos informatizados para facilitar la tarea. Al respecto, en las normas deben preverse los procedimientos necesarios para levantar las restricciones que pesen sobre la divulgación de información confidencial, previstas en los artículos 24 y 25.4 **[**hiperenlaces**]** de la Ley Modelo, en particular, determinar si el órgano independiente es el órgano competente del Estado promulgante para levantar esas restricciones, o si debe solicitar la orden para levantarlas a un tribunal u otro órgano competente del Estado promulgante;

k) Las normas para regular el acceso de todos los participantes en las actuaciones del recurso al expediente de este (que, con arreglo al artículo 67.8, comprende el expediente del proceso de contratación), entre otras cosas, por ejemplo, la exigencia de que demuestren su interés en los documentos a los cuales solicitan acceso; esa medida tiene por objeto permitir que el órgano independiente ejerza un control eficaz del procedimiento y evitar que los proveedores o contratistas lleven a cabo búsquedas exhaustivas en los documentos en el caso de que descubran cuestiones de importancia;

l) La manera de tratar la información reservada, entre otras cosas en el contexto de la adopción de decisiones y el despacho de notificaciones y en lo que respecta a dar acceso al expediente a los participantes en las actuaciones.

4. En el contexto del apartado 9 i), en el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables del Estado promulgante se deberían abordar las cuestiones relacionadas con la cuantificación de las pérdidas sufridas en el proceso

de contratación. Al respecto, debe tenerse en cuenta el trato que se da en el derecho interno a las pérdidas puramente económicas, de manera de lograr uniformidad en la determinación de las indemnizaciones en todo el Estado de que se trate (incluso el grado en que la indemnización dependa de que el solicitante pruebe que habría ganado el contrato en cuestión si no hubiera sido por el incumplimiento de las normas por parte de la entidad adjudicadora). La posibilidad de recibir una indemnización puede aumentar el riesgo de promover recursos especulativos y de perturbar el proceso de adjudicación. También puede aumentar el riesgo de abuso si la facultad para otorgar indemnizaciones se ha conferido a una entidad pequeña o a unas pocas personas. Por consiguiente, las reglamentaciones aplicables pueden exigir que se supervise la gestión del régimen de indemnización en los procedimientos de recurso, especialmente si se trata de un sistema cuasi judicial incipiente. Eso debería complementarse con un examen periódico del mecanismo de recurso en su totalidad para cerciorarse de que esté funcionando eficazmente en lo que respecta a permitir y alentar, cuando proceda, a los proveedores o contratistas a recurrir a él.

Artículo 68. Derechos reconocidos, en todo recurso interpuesto, a los demás participantes en el proceso objeto del recurso [\[hiperenlace**\]](#)**

1. En el reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables debería explicarse que el párrafo 1 tiene por objeto dar la posibilidad a todos los proveedores o contratistas “que participen en el proceso de contratación” de participar en las actuaciones abiertas a raíz del recurso, siempre y cuando participaran en el proceso en cuestión en el momento de interponerse el recurso. Así pues, se excluye a todo el que haya sido eliminado en la etapa de precalificación u otra etapa similar del proceso, salvo que esa medida constituya un acto o decisión de la entidad adjudicadora con la que guarde relación el recurso. Eso está basado, como se indicó anteriormente en el contexto del artículo 64, en la noción de que se reconoce el derecho a participar en las actuaciones a todo proveedor o contratista, u otro posible participante, que pruebe que sus intereses pueden verse afectados por el recurso interpuesto. También debería preverse la posibilidad de que otros interesados participaran en el procedimiento de recurso, ya que la entidad adjudicadora está interesada en que toda queja se ventile y se le dé a conocer la información correspondiente lo antes posible. El reglamento de la contratación pública u otras reglamentaciones aplicables pueden establecer una nomenclatura adecuada para identificar con más precisión a los diversos participantes.

2. En las normas aplicables a la gestión de las actuaciones por la entidad adjudicadora y el órgano independiente, respectivamente, examinadas anteriormente en el contexto de los artículos 66 y 67, debería preverse el respeto del principio de las garantías procesales durante el procedimiento de recurso y establecerse los derechos de todos los participantes en las actuaciones correspondientes, diferenciando los derechos más amplios del autor de la solicitud y de la entidad adjudicadora de los de otros interesados, y los derechos de esos dos grupos de los de toda otra persona que pueda estar presente durante las audiencias públicas (como los representantes de la prensa). Todo eso tiene por objeto lograr que las actuaciones puedan seguir su curso con la debida fluidez y que los proveedores o contratistas puedan participar efectivamente.

Artículo 69. Confidencialidad de las actuaciones abiertas en la sustanciación de un recurso [hiperenlace**](#)**

Las cuestiones que deben reglamentarse son las mencionadas anteriormente en el contexto de los artículos 24, 25.4, 66 y 67.

**B. Nota de la Secretaría sobre el glosario de términos relacionados
con la contratación pública utilizados en la Ley Modelo
de la CNUDMI sobre la Contratación Pública**

(A/CN.9/771)

[Original: inglés]

1. Durante la preparación de una guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública de 2011¹, se decidió publicar por separado y poner a disposición de los interesados en el sitio web de la CNUDMI un glosario de términos relacionados con la contratación pública utilizados en la Ley Modelo². En la Guía para la incorporación al derecho interno aprobada por la Comisión en su 45º período de sesiones, celebrado en 2012³, se observa en este contexto lo siguiente:

“El presente glosario incluirá descripciones de términos que no han sido definidos en la Ley Modelo, pero que se utilizan habitualmente en el ámbito de la contratación pública por proveedores, contratistas, funcionarios encargados de la contratación y sus asesores; también se examinarán términos que en la Ley Modelo pueden tener un significado distinto al que se les da en otros instrumentos internacionales o regionales de reglamentación de la contratación pública⁴.”

Por la presente nota, la Secretaría somete un proyecto de glosario a la consideración de la Comisión.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), anexo I.*

² *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 18, y párrs. 19 l) y 36 de A/CN.9/745.

³ *Ibid.*, párr. 46.

⁴ Párr. 8 de la introducción al capítulo I de la Ley Modelo. El texto de la Guía aprobada por la Comisión puede consultarse en la fecha de publicación del presente documento en www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2012Guide.html.

Glosario de términos relacionados con la contratación pública utilizados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública de 2011 (la “Ley Modelo”)¹

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
1.	Oferta anormalmente baja (artículo 20 [**hiperenlace**])	Oferta cuyo precio, junto con los demás elementos constitutivos de la oferta, resulta tan anormalmente bajo respecto del objeto del contrato adjudicable que suscita dudas en la entidad adjudicadora acerca de la aptitud del proveedor o contratista para cumplir el contrato. Para una explicación de los términos “oferta”, “elementos constitutivos de la oferta”, “objeto del contrato adjudicable”, “entidad adjudicadora”, “proveedor o contratista” y “contrato”, véase ## 83, 14, 82, 62, 85 y 59 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	• una oferta anormalmente inferior a las otras ofertas presentadas (Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC)² (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994, artículo XIII(4(a)) • una oferta cuyo precio sea anormalmente más bajo que los precios de las demás ofertas presentadas (texto revisado del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994³ (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012), artículo XV(6)) • oferta anormalmente baja (directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo⁴, artículo 57; directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo⁵, artículo 55)

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto periodo de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), anexo I.*

² Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC), negociado paralelamente a la Ronda Uruguay en 1994, y que entró en vigor el 1 de enero de 1996 (véase el anexo 4 b) del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, disponible en la fecha de publicación del presente glosario en www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gpr-94.pdf.

³ El 15 de diciembre de 2011, los negociadores llegaron a un acuerdo sobre los resultados de la renegociación del Acuerdo sobre Contratación Pública. Esta decisión política se confirmó el 30 de marzo de 2012 mediante la adopción formal de la Decisión sobre los resultados de las negociaciones celebradas de conformidad con el párrafo 7 del artículo XXIV del Acuerdo sobre Contratación Pública (GPA/113). El texto revisado está disponible en la fecha de publicación del presente glosario en www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/gp_gpa_s.htm.

⁴ Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (*Diario Oficial de la Unión Europea*, núm. L 134, de 30 de abril de 2004, pág. 1. Disponible en la fecha de publicación del presente glosario en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2004/L_134/L_13420040430es00010113.pdf.

⁵ Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (*Diario Oficial de la Unión Europea*, núm. L 134, de 30 de abril de 2004, pág. 114. Disponible en la fecha de publicación del presente glosario en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2004/L_134/L_13420040430es01140240.pdf).

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
2.	Apelación (artículo 64 [**hiperenlace**])	Presentación ante una autoridad competente de una solicitud de impugnación de una decisión emitida en un procedimiento de recurso. Para la explicación del término “procedimiento de recurso”, véase # 8 <i>infra</i> [**hiperenlace**].	• revisión administrativa o judicial (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo XVIII:1) • recurso ante un órgano no jurisdiccional y recurso jurisdiccional (directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo⁶, artículo 2 (9))
3.	Recurso de reconsideración presentado ante la entidad adjudicadora (artículo 66 [**hiperenlace**])	Procedimiento de recurso iniciado por un proveedor o contratista que sostenga haber sufrido o correr el riesgo de sufrir un daño o perjuicio imputable a una decisión o medida, supuestamente contraria al régimen de contratación del Estado promulgante, que la entidad adjudicadora haya adoptado (un “proveedor o contratista agraviado”) mediante la presentación, ante la entidad adjudicadora, de un recurso de reconsideración contra toda decisión o medida adoptada por esa entidad en el curso de la contratación. Para la explicación de los términos “procedimiento de recurso”, “proveedor o contratista” y “entidad adjudicadora”, véase ## 8, 85 y 62 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	• revisión inicial de una impugnación por un órgano distinto de una de las autoridades indicadas en el párrafo 4 [autoridad administrativa o judicial] (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo XVIII:5) • interposición de recurso con el poder adjudicador (directiva 2007/66/CE, artículo 1 (5)) • reconsideración por la entidad adjudicadora (Ley Modelo de la CNUDMI de 1994 sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios⁷ (la “Ley Modelo de 1994”, artículo 53)
4.	Recurso de revisión ante un órgano independiente (artículo 67 [**hiperenlace**])	Procedimiento de recurso iniciado por un proveedor o contratista agraviado mediante la presentación, ante el órgano independiente, de una solicitud para que reconsidere una decisión o medida adoptada por la entidad adjudicadora en el curso de la contratación, o reconsidere el hecho de que dicha entidad no haya emitido tal decisión, con arreglo al artículo 66 de la Ley Modelo, dentro de los plazos prescritos en ese artículo. Para la explicación del término “proveedor o contratista agraviado”, véase # 4 <i>supra</i> [**hiperenlace**]. Para la explicación de los términos “órgano independiente”, “procedimiento de recurso” y “entidad adjudicadora”, véase ## 37, 8 y 62 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	• revisión administrativa por un órgano de revisión que no sea un tribunal (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo XVIII:6) • recurso ante un órgano no jurisdiccional independiente (directiva 2007/66/CE, artículo 2(9)) • recurso administrativo jerárquico (Ley Modelo de 1994, artículo 54)

⁶ Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007 por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos (*Diario Oficial de la Unión Europea*, núm. L 335, de 20 de diciembre de 2007, pág. 31. Disponible en la fecha de publicación del presente glosario en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:335:0031:0046:Es:PDF>).

⁷ El texto de la Ley Modelo de 1994 figura en el anexo I del informe de la CNUDMI sobre la labor realizada en su 27º periodo de sesiones (*Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo noveno período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/49/17)*), y también está disponible en www.uncitral.org.

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
5.	Adjudicación de un contrato de adquisición o concertación de un acuerdo marco (artículos 22 y 23 [**hiperenlaces**])	Etapa final del procedimiento de contratación regulado por la Ley Modelo, que culmina con la celebración y entrada en vigor de un contrato de adquisición o de un acuerdo marco entre la entidad adjudicadora y el (los) proveedor(es) o contratista(s) seleccionado(s). Para la explicación de los términos “contrato de adquisición”, “acuerdo marco”, “entidad adjudicadora” y “proveedor o contratista”, véase ## 59, 31, 62 y 85 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	• adjudicación de un contrato y concertación de un acuerdo marco (directiva 2004/17/CE, artículo 43, y directiva 2004/18/CE, artículo 35(4)) • adjudicaciones de contratos (Ley Modelo de 1994, artículo 14)
6.	Mejores ofertas definitivas (artículos 49.11 y 51.3 [**hiperenlaces**])	Ofertas definitivas presentadas por proveedores o contratistas que siguen participando en el procedimiento de contratación una vez concluida la etapa del diálogo del proceso abierto por el método de la solicitud de propuestas con diálogo, o la etapa de negociación del procedimiento de negociación competitiva. Para la explicación de los términos “oferta”, “proveedor o contratista” y “negociación competitiva”, véase ## 83, 85 y 12 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	ofertas definitivas (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994, artículo XIV; directiva 2004/18/CE, artículo 29)
7.	Cancelación de la contratación (artículo 19 [**hiperenlace**])	Decisión adoptada por la entidad adjudicadora en el curso de cualquier procedimiento de contratación de no proseguir con dicho procedimiento. Para la explicación del término “entidad adjudicadora”, véase # 62 <i>infra</i> [**hiperenlace**] .	rechazo de todas las ofertas, propuestas o cotizaciones (Normas sobre selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial, versión de 2010 ⁸ (“Normas sobre selección y contratación de consultores del Banco Mundial (Normas de Consultores)”); Ley Modelo de 1994, artículo 12)
8.	Procedimientos de recurso (capítulo VIII [**hiperenlace**])	Procedimientos iniciados por un proveedor o contratista agraviado ante la entidad adjudicadora, un órgano independiente o un tribunal contra una decisión o medida de la entidad adjudicadora y cualquier recurso o apelación ulteriores ante un órgano competente del Estado contra cualquier decisión adoptada en el procedimiento de recurso. Para la explicación del término “proveedor o contratista agraviado”, véase # 4 <i>supra</i> [**hiperenlace**] . Para la explicación de los términos “entidad adjudicadora” y “órgano independiente”, véase ## 62 y 37 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	• procedimientos de revisión (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo XVIII y directiva 2007/66/CE, considerando 17) • vías de recurso (Ley Modelo de 1994, capítulo VI)

⁸ Disponibles en la fecha de publicación del presente glosario en <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20060656~menuPK:93977~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html>.

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
9.	Aclaraciones y modificaciones del pliego de condiciones (artículo 15 [**hiperenlace**])	Aclaraciones: toda explicación proporcionada por la entidad adjudicadora a los proveedores o contratistas acerca del pliego de condiciones. Modificaciones: cualesquiera correcciones u otras modificaciones realizadas por la entidad adjudicadora al pliego de condiciones. Para la explicación de los términos “entidad adjudicadora”, “proveedor o contratista” y “pliego de condiciones”, véase ## 62, 85 y 80 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	• respuesta a solicitudes de explicaciones relativas al pliego de condiciones y a solicitudes de información de otro tipo (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994, artículo XII) • procedimiento de aclaración (Normas sobre selección y contratación de consultores del Banco Mundial (Normas de Consultores))
10.	Acuerdo marco cerrado (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición e) ii))	Definido en la Ley modelo como: “Todo acuerdo marco en el que no pueda entrar a ser parte ningún proveedor o contratista que no sea inicialmente parte en dicho acuerdo.” Para la explicación de los términos “proveedor o contratista” y “acuerdo marco”, véase ## 85 y 31 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	
11.	Información reservada (artículos 2 [**hiperenlace**] , definición l), 7 y 24 [**hiperenlaces**])	Información definida como reservada por un Estado promulgante de conformidad con su derecho interno a la que, en virtud de las leyes o reglamentos pertinentes, solo pueden tener acceso determinadas categorías de personas.	
12.	Negociación competitiva (artículos 30.4, 34.3 y 51 [**hiperenlaces**])	Método de contratación al que se puede recurrir en circunstancias muy limitadas (en casos de urgencia, de emergencia y para la protección de los intereses de seguridad esenciales del Estado cuando el uso de otros métodos de contratación no sea apropiado) y que implica: a) una notificación pública previa al proceso de contratación; b) una negociación concomitante de las condiciones del contrato adjudicable por parte de la entidad adjudicadora con un número suficiente de proveedores o contratistas para garantizar que haya una verdadera competencia; c) la presentación por los proveedores o contratistas participantes de las mejores ofertas definitivas respecto de todos los aspectos de sus propuestas que se estén negociando con la entidad adjudicadora; d) el examen y la evaluación de las mejores ofertas definitivas por parte de la entidad adjudicadora; y e) la selección del ganador. Para la explicación del término “mejores ofertas definitivas”, véase # 6 <i>supra</i> [**hiperenlace**] . Para la explicación de los términos “contratación”, “entidad adjudicadora”, “proveedor o contratista”, “examen” y “evaluación”, véase ## 58, 62, 85, 29 y 27 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
13.	Condiciones de empleo (capítulo II, sección I [**hiperenlace**])	Un conjunto de requisitos mínimos que deben cumplirse para que la entidad adjudicadora pueda emplear un método de contratación distinto de la licitación abierta. Para la explicación de los términos “entidad adjudicadora” y “licitación abierta”, véase ## 62 y 49 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	casos que justifican el empleo (directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE; Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012)
14.	Elementos constitutivos de la oferta (artículos 10, 11, 20 y 39 h) [**hiperenlaces**])	a) Precio (el costo del objeto del contrato adjudicable, que puede abarcar también gastos de transporte y de seguros, derechos de aduanas e impuestos; en caso de que no sea así, esos elementos pueden interpretarse como elementos constitutivos separados de la oferta, véase a este respecto el artículo 39 h) [**hiperenlace**]); b) Los gastos de funcionamiento, de mantenimiento y de reparación de los bienes o de las obras, así como el plazo para la entrega de los bienes, la terminación de las obras o la prestación de los servicios, las características del objeto del contrato adjudicable, como pudieran ser sus características funcionales y ecológicas, las condiciones de pago y las garantías dadas respecto del objeto del contrato adjudicable; c) De ser pertinentes en la contratación realizada con arreglo a los artículos 47, 49 y 50 de la Ley Modelo [**hiperenlaces**], la experiencia, la fiabilidad y la competencia profesional y de gestión del proveedor o contratista, así como del personal que intervenga en la entrega del objeto del contrato adjudicado; d) Cualesquiera otros elementos de la oferta examinados o evaluados con arreglo a los criterios y procedimientos estipulados por la entidad adjudicadora en el pliego de condiciones de conformidad con los artículos 10 y 11 de la Ley Modelo [**hiperenlaces**]. Para la explicación de los términos “objeto del contrato adjudicable”, “oferta”, “bienes”, “obras”, “servicios”, “contratación”, “proveedor o contratista”, “examen”, “evaluación” y “pliego de condiciones”, véase ## 82, 83, 35, 15, 76, 58, 85, 29, 27 y 80 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	entre los elementos constitutivos de la oferta pueden figurar los siguientes: a) el ahorro que permita el procedimiento de fabricación de los productos, la prestación de servicios o el procedimiento de construcción; b) las soluciones técnicas adoptadas y/o las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras; c) la originalidad de los suministros, servicios u obras propuestos por el licitador; d) el respeto de las disposiciones vigentes relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo en el lugar en que se vaya a llevar a cabo la obra, el servicio o el suministro; e) la posible obtención de una ayuda estatal por parte del licitador. (directiva 2004/17/CE, artículo 57, y directiva 2004/18/CE, artículo 55)

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
15.	Obras (artículo 39 [**hiperenlace**])	Todos los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación o renovación de edificios, estructuras o instalaciones, como la preparación del terreno, la excavación, la erección, la edificación, la instalación de equipo o materiales, la decoración y el acabado, así como los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros servicios similares estipulados en el contrato a que se refiere la adjudicación, si el valor de esos servicios no excede del de las propias obras (véase el artículo 2, definición d) de la Ley Modelo de 1994). Para la explicación del término “contrato a que se refiere la adjudicación”, véase # 59 <i>infra</i> [**hiperenlace**].	• servicio de construcción, obra de ingeniería civil o de construcción (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo I(c)) • obras de construcción o de ingeniería civil (directiva 2004/18/CE, artículo 1(2)b) • obras (Normas sobre adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, versión de enero de 2011⁹ (“Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial”))
16.	Moneda (artículo 39 [**hiperenlace**])	Definida en el artículo 2 de la Ley Modelo [**hiperenlace**] como “toda unidad monetaria de cuenta”.	moneda nacional o una divisa plenamente convertible (véanse las Normas sobre selección y contratación de consultores del Banco Mundial (Normas de Consultores))
17.	Plazo para la presentación de solicitudes/ofertas (artículo 14 [**hiperenlace**])	Fecha y hora después de las cuales la entidad adjudicadora no aceptará solicitudes de precalificación o de preselección ni ofertas para su examen y evaluación. Para la explicación de los términos “oferta”, “entidad adjudicadora”, “examen” y “evaluación”, véase ## 83, 62, 29 y 27 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	plazos (directiva 2004/17/CE, artículo 45, y directiva 2004/18/CE, artículo 38)
18.	Descripción del objeto del contrato adjudicable (artículo 10 [**hiperenlace**])	Características técnicas, de calidad y de rendimiento del objeto del contrato adjudicable y cualesquiera otros requisitos que deba satisfacer la oferta para ser considerada conforme, indicados por la entidad adjudicadora en el pliego de condiciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Modelo [**hiperenlace**]. Para la explicación de los términos “objeto del contrato adjudicable”, “oferta”, “entidad adjudicadora” y “pliego de condiciones”, véase ## 82, 83, 62 y 80 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	

⁹ Disponibles en la fecha de publicación del presente glosario en http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Procurement_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf.

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
19.	Convocatoria directa (artículos 2 [**hiperlance**] , definición b), 34 y 35 [**hiperlances**])	Definida en la Ley Modelo como: “Toda convocatoria que vaya directamente dirigida a uno solo o a un número restringido de proveedores o contratistas, pero este término no será aplicable a las convocatorias dirigidas al número limitado de proveedores o contratistas que resulte de un procedimiento de precalificación o preselección.” Para la explicación de los términos “convocatoria”, “proveedor o contratista”, “precalificación” y “preselección”, véase ## 79, 85, 53 y 55 <i>infra</i> [**hiperlances**] .	invitación directa y sin anuncio público (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial, párrafo 3.2)
20.	Expediente del procedimiento de adjudicación (artículo 25 [**hiperlance**])	Expediente escrito exhaustivo sobre determinado proceso de contratación que incluye decisiones, una descripción de las acciones y cualquier otra información relativa a la contratación con documentación de apoyo. Para la explicación del término “contratación”, véase # 58 <i>infra</i> [**hiperlances**] .	- la documentación y los informes de los procedimientos de licitación y de las adjudicaciones de contratos relacionados con las contrataciones abarcadas, con inclusión de los informes exigidos conforme al artículo XIII (sobre contratos adjudicados mediante licitación restringida, que contienen el nombre de la entidad contratante, el valor y la clase de los bienes o servicios objeto del contrato y una indicación de las circunstancias y condiciones que justificaban el uso de la licitación restringida), así como, en caso de que la contratación abarcada se haya realizado por medios electrónicos, los datos que permitan el adecuado rastreo de su tramitación (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo XVI(3)) - información que ha de conservarse sobre los contratos adjudicados (directiva 2004/17/CE, artículo 50) - expedientes para examen posterior (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial) - expediente del proceso de contratación (Ley Modelo de 1994, artículo 11) - excepciones convenidas al trato nacional y la no discriminación (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo V:4) - licitación pública nacional (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial, párrafo 3.3)
21.	Contratación nacional (artículo 2 [**hiperlance**] , definición c))	Definida en el artículo 2 de la Ley Modelo como “un procedimiento abierto exclusivamente a la participación de proveedores o contratistas nacionales, conforme al artículo 8 de la presente Ley”. Para la explicación de los términos “contratación” y “proveedor o contratista”, véase ## 58 y 85 <i>infra</i> [**hiperlances**] .	
22.	Proveedores o contratistas nacionales (artículos 2, 11 y 33 [**hiperlances**])	En el contexto de un Estado determinado, proveedores o contratistas registrados como entidades jurídicas en ese Estado. Para la explicación del término “proveedor o contratista”, véase # 85 <i>infra</i> [**hiperlance**] .	

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
23.	Bienes de origen interno (artículo 11 [**hiperenlace**])	En el contexto de un Estado determinado, bienes de fabricación local (la legislación indica por lo general el porcentaje mínimo de contenido local requerido (mano de obra, materias primas, y componentes) para que estos bienes tengan el carácter de tales). Para la explicación del término “bienes”, véase # 35 <i>infra</i> [**hiperenlace**] .	• productos nacionales (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994, párr. 2 del preámbulo y artículos III(1)(a) y XIII(4)(b)) • bienes fabricados en el país del prestatario (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)
24.	Subasta electrónica inversa (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición d), artículo 31 y capítulo VI [**hiperenlace**])	Definida en la Ley Modelo como: “Técnica informática de contratación en tiempo real, de la que podrá valerse la entidad adjudicadora para seleccionar la oferta ganadora, consistente en que los proveedores o contratistas vayan presentando, durante un plazo establecido, ofertas cada vez más bajas, cuya evaluación será automática.” Para la explicación de los términos “entidad adjudicadora”, “oferta ganadora”, “proveedor o contratista” y “evaluación”, véase ## 62, 84, 85 y 27 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	subasta electrónica (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo XIV; directiva 2004/18/CE, artículo 54)
25.	Subasta electrónica inversa como método de contratación en sí (artículos 31.1 y 53 [**hiperenlaces**])	Subasta electrónica inversa utilizada como método de contratación separado. Para la explicación de los términos “subasta electrónica inversa” y “método de contratación”, véase # 24 <i>supra</i> y # 44 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	subasta electrónica (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo XIV; directiva 2004/18/CE, artículos 1 (7) y 54)
26.	Subasta electrónica inversa como una fase (artículos 31.2 y 54 [**hiperenlaces**])	Subasta electrónica inversa utilizada como la fase que antecede a la adjudicación del contrato en otro método de contratación o en un procedimiento de acuerdo marco con segunda etapa competitiva. Para la explicación de los términos “subasta electrónica inversa”, “método de contratación” y “procedimiento de acuerdo marco con segunda etapa competitiva”, véase # 24 <i>supra</i> y ## 44 y 33 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	subasta electrónica (directiva 2004/18/CE, artículo 54)
27.	Evaluación (artículos 11, 16, 22, 25 y 43 [**hiperenlaces**])	Análisis comparativo de las ofertas de conformidad con los criterios y procedimientos enunciados en el pliego de condiciones a fin de determinar la oferta ganadora. Para la explicación de los términos “oferta”, “pliego de condiciones” y “oferta ganadora”, véase ## 83, 80 y 84 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	evaluación (directiva 2004/18/CE, considerando 46)

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
28.	Criterios de evaluación (artículo 11 [**hiperenlace**])	Criterios utilizados en la evaluación conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones para la determinación de la oferta ganadora. Para la explicación de los términos “evaluación”, “pliego de condiciones” y “oferta ganadora”, véase # 27 <i>supra</i> y ## 80 y 84 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	- los criterios en que se fundará la adjudicación del contrato (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994, artículo XII(2)(h)) - criterios de adjudicación del contrato o criterios de adjudicación (directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, considerandos 1 y 51) - criterios de selección (Normas sobre selección y contratación de consultores del Banco Mundial (Normas de Consultores)) - criterios que habrá de emplear la entidad adjudicadora para determinar la oferta ganadora; criterios para la evaluación de las propuestas (Ley Modelo de 1994, artículos 27 e) y 39)
29.	Examen (artículos 11, 16, 25 y 43 [**hiperenlaces**])	Determinación de la idoneidad de los proveedores o contratistas y de la conformidad de sus ofertas con los criterios especificados en el pliego de condiciones. El proceso se realiza sobre la base de la aptitud o no aptitud para responder a esos criterios y no implica una comparación de ofertas como en la evaluación. Para la explicación de los términos “proveedor o contratista”, “oferta”, “pliego de condiciones” y “evaluación”, véase # 27 <i>supra</i> y ## 85, 83 y 80 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	
30.	Contratos próximamente adjudicables (artículo 6 [**hiperenlace**])	Actividades de contratación planificadas para los próximos meses o años.	- contrato programado (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994, artículo IX.7 (véase también “contrato proyectado”) y Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo VII (véase también “contratación prevista”)) - contrataciones futuras (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo VII) “perfil del comprador” en el que se dan a conocer el tipo y el valor de los contratos cuya adjudicación está prevista (directiva 2004/17/CE, artículo 41, y directiva 2004/18/CE, artículo 35)

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
31.	Acuerdo marco (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición e i))	Todo acuerdo que se concierte, al concluirse con éxito la primera etapa del método de contratación con arreglo a un acuerdo marco, entre la entidad adjudicadora y uno o más proveedores o contratistas seleccionados. Para la explicación de los términos “entidad adjudicadora”, “proveedor o contratista” y “contratación con arreglo a un acuerdo marco”, véase ## 62, 85 y 32 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	
32.	Contratación con arreglo a un acuerdo marco (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición e))	Definida en la Ley Modelo como: “Todo proceso que se programe en dos etapas: la primera para seleccionar a uno o más proveedores o contratistas que vayan a ser partes en un acuerdo marco concertado con una entidad adjudicadora, y la segunda para adjudicar algún contrato, con arreglo a ese acuerdo marco, a un proveedor o contratista que sea parte en el acuerdo.” Para la explicación de los términos “proveedor o contratista”, “entidad adjudicadora” y “acuerdo marco”, véase # 31 <i>supra</i> y ## 85 y 62 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	
33.	Contratación con arreglo a un acuerdo marco con segunda etapa competitiva (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición e) iv))	Definida en la Ley Modelo como: “Todo proceso de adjudicación con arreglo al método del acuerdo marco, ya sea abierto o cerrado, entablado con más de un proveedor o contratista, en el que al no haber sido posible determinar, al concluirse el acuerdo marco, algunas de las condiciones de los contratos que se tenga previsto adjudicar, será preciso determinar o precisar esas condiciones en una segunda etapa competitiva.” Para la explicación de los términos “acuerdo marco cerrado” y “acuerdo marco”, véase ## 10 y 31 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para la explicación de los términos “acuerdo marco abierto”, “proveedor o contratista”, “contratos que se tenga previsto adjudicar” y “segunda etapa competitiva”, véase ## 48, 85, 58 y 74 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	
34.	Contratación con arreglo a un acuerdo marco sin segunda etapa competitiva (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición e) v))	Definida en la Ley Modelo como: “Proceso de adjudicación, con arreglo a un acuerdo marco cerrado, en el que se hayan de concretar, al concertarse el acuerdo marco, todas las condiciones de los contratos que se vayan a adjudicar.” Para la explicación de los términos “acuerdo marco cerrado” y “acuerdo marco”, véase ## 10 y 31 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para la explicación del término “contratos que se vayan a adjudicar”, véase # 58 <i>infra</i> [**hiperenlace**].	

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
35.	Bienes (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición j), y artículos 11 y 39 [**hiperenlace**])	Objetos de cualquier índole, incluidas las materias primas, los productos, el equipo, otros objetos en estado sólido, líquido o gaseoso y la electricidad, así como los servicios accesorios al suministro de esos bienes, siempre que el valor de los servicios no exceda del de los propios bienes (el Estado promulgante podrá añadir otras categorías de bienes) (véase el artículo 2, definición c), de la Ley Modelo de 1994).	productos (directiva 2004/18/CE)
36.	Frecuencia indeterminable o reiterada (artículo 32 [**hiperenlace**] , párrafo 1 a))	Una de las condiciones para el empleo de la contratación con arreglo a un acuerdo marco establecida en la Ley Modelo que presupone que la cantidad o la oportunidad del suministro del objeto del contrato adjudicable que se requerirá durante cierto período de tiempo no se conocen con antelación. Para la explicación del término “contratación con arreglo a un acuerdo marco”, véase # 32 <i>supra</i> [**hiperenlace**] . Para la explicación del término “objeto del contrato adjudicable”, véase # 82 <i>infra</i> [**hiperenlace**] .	
37.	Órgano independiente (capítulo VIII [**hiperenlace**])	Un órgano competente del Estado promulgante que es independiente de la entidad adjudicadora y al que el Estado le encomienda el examen de los recursos de revisión y la adopción de medidas en lo que respecta a esos recursos y al proceso de contratación con el que los recursos se relacionan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Modelo. Para la explicación del término “recursos de revisión”, véase # 4 <i>supra</i> [**hiperenlace**] . Para la explicación del término “entidad adjudicadora”, véase # 62 <i>infra</i> [**hiperenlace**] .	• autoridad independiente (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo XVIII:4) • un órgano de primera instancia, independiente del poder adjudicador (directiva 2007/66/CE, artículo 2(3)) • órgano administrativo (Ley Modelo de 1994, artículo 54)
38.	Propuestas indicativas (artículo 60 [**hiperenlace**])	Propuestas presentadas por proveedores o contratistas para pasar a ser partes en el acuerdo marco abierto. Para la explicación de los términos “propuesta”, “proveedor o contratista” y “acuerdo marco abierto”, véase ## 83, 85 y 48 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	
39.	Ofertas iniciales (artículo 53 [**hiperenlace**])	Ofertas presentadas para su examen o evaluación antes de la celebración de la subasta electrónica inversa como método de contratación en sí. Para la explicación de los términos “examen”, “evaluación” y “subasta electrónica inversa como método de contratación en sí”, véase ## 29, 27 y 25 <i>supra</i> [**hiperenlaces**] .	

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
40.	Ofertas iniciales (artículo 48 [**hiperenlace**])	Ofertas que contienen propuestas en las que no se hace mención del precio de la oferta, presentadas por proveedores o contratistas en la primera etapa del procedimiento de licitación en dos etapas para que la entidad adjudicadora las examine y entable conversaciones con los proveedores o contratistas a fin de perfeccionar aspectos de la descripción del objeto del contrato adjudicable y formularlos con la precisión exigida por el artículo 10 de la Ley Modelo. Para la explicación de los términos “examen” y “descripción del objeto del contrato adjudicable”, véase ## 29 y 18 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para la explicación de los términos “precio de la oferta”, “proveedor o contratista”, “licitación en dos etapas” y “entidad adjudicadora”, véase ## 86, 85, 88 y 62 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	• invitación a participar en relación con el contrato previsto (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994, artículo IX) • anuncio de la contratación prevista (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo I-k) • invitación a presentar ofertas, a participar en un procedimiento restringido o negociado, a negociar o a participar en el diálogo (directiva 2004/17/CE, artículos 1(2)(7) y 47, y directiva 2004/18/CE, artículos 1(2)(8), 33 y 40) • carta de invitación (Normas sobre selección y contratación de consultores del Banco Mundial (Normas de Consultores))
41.	Invitación a licitar, a presentar ofertas o a participar en procedimientos de solicitud de propuestas o en subastas electrónicas inversas (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición p))	Información mínima sobre todo proceso de contratación publicada o proporcionada a los proveedores o contratistas para permitirles evaluar su interés en participar en ese proceso y presentar ofertas con arreglo a los requisitos enunciados en la invitación. Para la explicación de los términos “proceso de contratación” y “proveedor o contratista”, véase ## 58 y 85 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
42.	Conducta dilatoria o irresponsable de la entidad adjudicadora (artículo 19 [**hiperenlace**])	El término se utiliza en la Ley Modelo en el contexto de la cancelación de la contratación (artículo 19 [**hiperenlace**]): la entidad adjudicadora podrá ser responsable de la cancelación de la contratación si esa cancelación es imputable a una conducta dilatoria o irresponsable de su parte, por ejemplo, cuando la entidad adjudicadora cancela la contratación después de la apertura de las ofertas a sabiendas de que un proveedor o contratista favorecido no ganaría, o cuando la entidad adjudicadora cancela una licitación abierta intencionalmente con la finalidad de utilizar un método de contratación alternativo con respecto a la licitación abierta en la nueva convocatoria a licitación, como lo permite la Ley Modelo en los párrafos 1 (b) y 2 (d) del artículo 30 [**hiperenlace**], o cuando la entidad adjudicadora haya iniciado la contratación sin una planificación adecuada. Para la explicación del término “cancelación de la contratación”, véase # 7 <i>supra</i> [**hiperenlace**]. Para la explicación de los términos “contratación”, “entidad adjudicadora”, “proveedor o contratista”, “licitación abierta” y “método de contratación”, véase ## 58, 62, 85 y 44 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	
43.	Margen de preferencia (artículo 11 [**hiperenlace**])	Técnica aplicada en la evaluación de las ofertas que permite a la entidad adjudicadora otorgar a algunos proveedores o contratistas o bienes (generalmente proveedores o contratistas nacionales o bienes de origen interno) un trato más favorable que a otros. Cuando la diferencia en el precio (o el precio combinado con la calificación de la calidad) entre las ofertas de un grupo favorecido (o con respecto a bienes favorecidos) y la oferta con el precio más bajo o la más ventajosa está dentro de los límites del margen de preferencia, una oferta del grupo favorecido (o con respecto a bienes favorecidos) se establece como ganadora de conformidad con las normas relativas al cálculo y la aplicación de un margen de preferencia que figuran en la legislación del Estado promulgante. Para la explicación de los términos “evaluación”, “bienes”, “proveedores o contratistas nacionales” y “bienes de origen interno”, véase ## 27, 35, 22 y 23 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para la explicación de los términos “oferta”, “entidad adjudicadora” y “proveedor o contratista”, véase ## 83, 62 y 85 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
44.	Método de contratación (artículo 27 [**hiperenlace**])	Manera de llevar a cabo la contratación, sujeta a un conjunto de condiciones de empleo y normas y procedimientos para la convocatoria y la determinación de la oferta ganadora. Para la explicación del término “condiciones de empleo”, véase # 13 <i>supra</i> [**hiperenlace**]. Para la explicación de los términos “contratación”, “convocatoria” y “oferta ganadora”, véase ## 58, 79 y 84 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	• métodos de contratación (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo VII(2)) • procedimientos (directiva 2004/18/CE, capítulo V)
45.	Declaración engañosa (artículo 9 [**hiperenlace**])	Afirmación o manifestación mediante palabras o actos que no concuerda con los hechos (por ejemplo, declaraciones incorrectas y reñidas con los hechos debido a ignorancia consciente o al hecho de hacer caso omiso temerariamente de la verdad, omisión del deber de revelar datos materiales o importantes). El término no pretende abarcar las declaraciones intencionalmente falsas a las que se hace referencia en otras partes de la Ley Modelo.	declaraciones falsas, falta de ética profesional o actos u omisiones que pongan en entredicho la integridad comercial del proveedor (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994 y Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012)
46.	Oferta más ventajosa (artículo 43 [**hiperenlace**])	La oferta ganadora seleccionada sobre la base de la evaluación del precio y otros criterios de evaluación y de conformidad con los procedimientos de evaluación de las ofertas enunciados en el pliego de condiciones conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Modelo [**hiperenlace**]. Para la explicación de los términos “evaluación” y “criterios de evaluación”, véase ## 27 y 28 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para la explicación del término “pliego de condiciones”, véase # 80 <i>infra</i> [**hiperenlace**].	• oferta económicamente más ventajosa (directiva 2004/18/CE, artículo 53(1)(a)) • la oferta que resulte con el costo evaluado más bajo; la oferta evaluada como la más baja (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial, párrafos 2.49 y 2.52) • la oferta calificada de más económica (Ley Modelo de 1994, artículo 34 (4) (b) (ii))
47.	Anuncio de la contratación (artículos 34 y 35 [**hiperenlaces**])	Anuncio publicado antes de la convocatoria directa (salvo en casos de solicitud de cotizaciones y urgencia) que contiene información sobre la contratación inminente (cuyos aspectos más importantes son el nombre y la dirección de la entidad adjudicadora, un resumen de las principales condiciones del contrato o acuerdo marco, una declaración sobre la limitación impuesta a la participación de proveedores o contratistas en el proceso de contratación, y el método de contratación que habrá de emplearse). Para la explicación de los términos “convocatoria directa”, “acuerdo marco” y “método de contratación”, véase ## 19, 31 y 44 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para la explicación de los términos “solicitud de cotizaciones”, “contratación”, “entidad adjudicadora”, “contrato”, “participación de proveedores o contratistas en el proceso de contratación” y “proveedores o contratistas”, véase ## 71, 58, 62, 59, 51 y 85 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	• anuncio de licitación (directiva 2004/18/CE, artículo 30(1)(a)) • Anuncio General de Adquisiciones y Anuncio Específico de Adquisiciones (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
48.	Acuerdo marco abierto (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición e) iii))	Definido en la Ley Modelo como: “Todo acuerdo marco en el que puedan subsiguientemente entrar a ser partes uno o más proveedores o contratistas que no lo fueran inicialmente.” Para la explicación del término “acuerdo marco”, véase # 31 <i>supra</i> [**hiperenlace**]. Para la explicación del término “proveedor o contratista”, véase # 85 <i>infra</i> [**hiperenlace**].	sistema dinámico de adquisición (directiva 2004/18/CE, artículo 1(5))
49.	Licitación abierta (capítulo III [**hiperenlace**])	Método de contratación estándar que entraña una convocatoria pública y no restringida y una especificación y descripción completas en el pliego de condiciones del objeto del contrato, a fin de que los proveedores o contratistas puedan preparar sus ofertas sobre una misma base; la divulgación completa a los proveedores o contratistas de los criterios que se aplicarán para la evaluación de las ofertas y para la selección de la oferta ganadora; la estricta prohibición de toda negociación entre la entidad adjudicadora y los proveedores o contratistas sobre el contenido de sus ofertas; la apertura pública de las ofertas al término del plazo para su presentación; y la notificación de toda formalidad requerida para la entrada en vigor del contrato adjudicado. Para la explicación de los términos “método de contratación”, “evaluación” y “término del plazo para su presentación”, véase ## 44, 27 y 17 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para la explicación de los términos “convocatoria”, “pliego de condiciones”, “proveedor o contratista”, “entidad adjudicadora”, “oferta ganadora”, “apertura de las ofertas” y “contrato adjudicado”, véase ## 79, 80, 85, 62, 84, 50 y 59 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	• procedimientos abiertos (directiva 2004/18/CE, artículo 1(11) (a)) • licitación pública internacional (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)
50.	Apertura de las ofertas (artículo 42 [**hiperenlace**])	Etapas del proceso de licitación que entraña la apertura pública de las ofertas y el anuncio del nombre y la dirección de cada proveedor o contratista cuya oferta sea abierta, así como el precio de la oferta, a los presentes en el acto de apertura. Para la explicación de los términos “proveedor o contratista” y “precio de la oferta”, véase ## 85 y 86 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	apertura de las ofertas (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
51.	Participación de proveedores o contratistas en el proceso de contratación (artículos 7, 8, 10, 15, 25, 54, 58 y 60 [**hiperenlaces**])	Participación de proveedores o contratistas en cualquier etapa del proceso de contratación, desde el momento de la presentación de una solicitud de precalificación, una solicitud de preselección o una oferta. Para la explicación de los términos “proveedor o contratista”, “precalificación”, “preselección” y “oferta”, véase ## 85, 53, 55 y 83 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	
52.	Plazo de vigencia de las ofertas (artículo 41 [**hiperenlace**])	Plazo durante el cual los proveedores o contratistas están obligados por las cláusulas y condiciones de sus ofertas. Para la explicación de los términos “proveedor o contratista” y “oferta”, véase ## 85 y 83 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	
53.	Precalificación (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición f), y artículo 18 [**hiperenlace**])	Definida en la Ley Modelo como: “Procedimiento enunciado en el artículo 18 de la presente Ley cuya finalidad es determinar, antes de la convocatoria, los proveedores o contratistas que estén calificados.” Para la explicación de los términos “convocatoria” y “proveedor o contratista”, véase ## 79 y 85 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	
54.	Documentos de precalificación artículo 2 [**hiperenlace**] , definición g), y artículo 18 [**hiperenlace**])	Definidos en la Ley Modelo como: “Documentos emitidos por la entidad adjudicadora con arreglo al artículo 18 de la presente Ley en los que se dan a conocer las condiciones para participar en el procedimiento de precalificación.” Para la explicación del término “precalificación”, véase # 53 <i>supra</i> [**hiperenlace**] . Para la explicación del término “entidad adjudicadora”, véase # 62 <i>infra</i> [**hiperenlace**] .	
55.	Preselección artículo 2 [**hiperenlace**] , definición h), y artículo 49 [**hiperenlace**] , párrafo 3)	Definida en la Ley Modelo como: “Procedimiento enunciado en el párrafo 3 del artículo 49 de la presente Ley cuya finalidad es determinar, antes de la convocatoria, un número limitado de proveedores o contratistas que sean los que mejor cumplan los criterios de calificación para la contratación pertinente.” Para la explicación de los términos “convocatoria”, “proveedor o contratista” y “contratación”, véase ## 79, 85 y 58 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
56.	Documentos de preselección (artículo 2 [**hiperlance**] , definición i), y artículo 49 [**hiperlance**] , párrafo 3)	Definidos en la Ley Modelo como: “Documentos emitidos por la entidad adjudicadora con arreglo al párrafo 3 del artículo 49 de la presente Ley en los que se dan a conocer las condiciones para participar en el procedimiento de preselección.” Para la explicación del término “preselección”, véase # 55 <i>supra</i> [**hiperlance**] . Para la explicación del término “entidad adjudicadora”, véase # 62 <i>infra</i> [**hiperlance**] .	
57.	Presentación de ofertas (artículo 40 [**hiperlance**])	Presentación, por proveedores o contratistas a la entidad adjudicadora, de ofertas por escrito, firmadas y en sobre sellado o en su equivalente electrónico que garantice el mismo nivel de seguridad, integridad, confidencialidad y autenticidad, de la manera, en el lugar y dentro del plazo estipulados por la entidad adjudicadora en el pliego de condiciones. Para la explicación de los términos “proveedor o contratista”, “entidad adjudicadora” y “pliego de condiciones”, véase ## 85, 62 y 80 <i>infra</i> [**hiperlances**] .	• presentación de las ofertas (directiva 2004/18/CE, artículo 1(8); Ley Modelo de 1994, capítulo III, sección II) • presentación de las ofertas (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)
58.	Contratación (artículo 2 [**hiperlance**] , definición j))	Definida en la Ley Modelo como: “Adquisición de bienes, obras o servicios por parte de una entidad adjudicadora.” Para la explicación de los términos “bienes” y “obras”, véase ## 35 y 15 <i>supra</i> [**hiperlances**] . Para la explicación de los términos “entidad adjudicadora” y “servicios”, véase ## 62 y 76 <i>infra</i> [**hiperlances**] .	
59.	Contrato adjudicado (artículo 2 [**hiperlance**] , definición k))	Definido en la Ley Modelo como: “Contrato celebrado entre la entidad adjudicadora y uno o más proveedores o contratistas a raíz de un proceso de contratación.” Para la explicación de los términos “entidad adjudicadora” y “proveedor o contratista”, véase ## 62 y 85 <i>infra</i> [**hiperlances**] .	contratos públicos (directiva 2004/18/CE, artículo 1-2 (a))

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
60.	Adjudicación de contratos con información reservada (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición l))	Definida en la Ley Modelo como: “Toda adjudicación de un contrato respecto del cual quepa autorizar a la entidad adjudicadora, a tenor del reglamento de la contratación pública u otra norma aplicable de derecho interno, a adoptar medidas especiales y a imponer requisitos especiales para amparar la información que se tenga por reservada.” Para la explicación del término “adjudicación de un contrato”, véase # 58 <i>supra</i> [**hiperenlace**] . Para la explicación de los términos “entidad adjudicadora” y “reglamento de la contratación pública”, véase ## 62 y 61 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	• contratos secretos o que requieren medidas especiales de seguridad (directiva 2004/18/CE, artículo 14) • contratos celebrados en el ámbito de la defensa y la seguridad (directiva 2009/81/CE¹⁰, artículo 2)
61.	Reglamento de la contratación pública (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición m))	Definido en la Ley Modelo como: “Toda norma reglamentaria que proceda adoptar conforme a lo previsto en el artículo 4 de la presente Ley.”	
62.	Entidad adjudicadora (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición n))	Definida en la Ley Modelo como: “ <i>Variante I</i> i) Todo departamento, organismo, órgano u otra dependencia administrativa, o toda subdivisión o agrupación de esas entidades públicas que adjudique contratos, salvo ...; [y] <i>Variante II</i> i) Todo departamento, organismo, órgano u otra dependencia de [la administración pública] <i>[todo otro término que se utilice para referirse a las entidades públicas del Estado promulgante]</i> , o toda subdivisión o agrupación de esas entidades que adjudique contratos, salvo ...; [y] ii) <i>[El Estado promulgante podrá indicar en este inciso y, de ser necesario, en incisos subsiguientes, otras entidades o empresas, o categorías de ellas, que hayan de incluirse en la definición de “entidad adjudicadora”];</i> ” Para la explicación del término “que adjudique contratos”, véase # 58 <i>supra</i> [**hiperenlace**] .	poderes adjudicadores (directiva 2004/18/CE, artículo 1(9))

¹⁰ Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (*Diario Oficial de la Unión Europea*, núm. L 216, 20 de agosto de 2009, pág. 76. Disponible en la fecha de publicación del presente glosario en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:ES:PDF>).

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
63.	Anuncio público de los contratos adjudicados (artículo 23 [**hiperenlace**])	Anuncio al público en general mediante la publicación en los medios de comunicación especificados en la legislación del Estado promulgante por el que se comunica el nombre del adjudicatario o, si se trata de un acuerdo marco, de los proveedores o contratistas con los que se haya concertado el acuerdo marco, así como el precio del contrato adjudicado. Para la explicación de los términos “contrato adjudicado” y “acuerdo marco”, véase ## 59 y 31 <i>supra</i> [**hiperenlaces**] .	• anuncios de contratos adjudicados (directiva 2004/17/CE, artículo 43 y anexo XVI) • anuncio sobre los resultados del procedimiento de adjudicación (directiva 2004/18/CE, artículo 35(4) y anexo VII A) • notificación de la adjudicación (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial, apéndice 1 [7])
64.	Contratación pública	Debe entenderse como contratación (véase # 58 <i>supra</i>).	
65.	Publicación internacional (artículos 18.2 y 33.2 [**hiperenlaces**])	Publicación en un medio de comunicación al que tengan amplio acceso los proveedores o contratistas internacionales. Para la explicación del término “proveedor o contratista”, véase # 85 <i>infra</i> [**hiperenlace**] .	• por ejemplo, publicación por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (directiva 2004/17/CE, artículo 42, y directiva 2004/18/CE, artículos 35 y 36 (2)) • por ejemplo, un Anuncio General de Adquisiciones en <i>United Nations Development Business (UNDB online)</i> (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial) • criterios sustantivos que deben tenerse en cuenta para verificar la idoneidad del contratista (directiva 2004/17/CE, artículos 52 a 54, y directiva 2004/18/CE, artículos 45 a 52)
66.	Criterios de idoneidad (artículo 9 [**hiperenlace**])	Criterios utilizados por la entidad adjudicadora a fin de determinar la elegibilidad de los proveedores o contratistas para participar en el proceso de contratación, tal como se enuncian en los documentos de precalificación o de preselección, cuando proceda, y en el pliego de condiciones. Para la explicación de los términos “documentos de precalificación” y “documentos de preselección”, véase ## 54 y 56 <i>supra</i> [**hiperenlaces**] . Para la explicación de los términos “proveedor o contratista” y “pliego de condiciones”, véase ## 85 y 80 <i>infra</i> [**hiperenlaces**] .	
67.	Ponderación (artículo 11 [**hiperenlace**])	Ponderación de cada criterio de evaluación en relación con los demás dada a conocer por la entidad adjudicadora en el pliego de condiciones. Para la explicación de los términos “entidad adjudicadora” y “criterios de evaluación”, véase ## 62 y 28 <i>supra</i> [**hiperenlaces**] . Para la explicación del término “pliego de condiciones”, véase # 80 <i>infra</i> [**hiperenlace**] .	• distinta ponderación, ponderación relativa de los criterios (directiva 2004/17/CE, párr. 55 del preámbulo y artículo 55(2), y directiva 2004/18/CE, párr. 46 del preámbulo y artículo 53(2)) • ponderación de los criterios de evaluación (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
68.	Solicitud de propuestas con negociación consecutiva (artículos 30.3 y 50 [**hiperenlaces**])	Método de contratación cuya principal característica distintiva es la negociación de las condiciones financieras de las ofertas tras haber concluido la evaluación de las características técnicas, de calidad y de rendimiento de las ofertas. Para la explicación de los términos “método de contratación” y “evaluación”, véase ## 44 y 27 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para la explicación del término “oferta”, véase # 83 <i>infra</i> [**hiperenlace**].	diálogo competitivo (directiva 2004/18/CE, artículo 1(11) (c))
69.	Solicitud de propuestas con diálogo (artículos 30.2 y 49 [**hiperenlaces**])	Método de contratación cuya principal característica distintiva es el diálogo con los proveedores o contratistas a fin de obtener la solución más satisfactoria para las necesidades de contratación. Para la explicación del término “método de contratación”, véase # 44 <i>supra</i> [**hiperenlace**]. Para la explicación del término “proveedor o contratista”, véase # 85 <i>infra</i> [**hiperenlace**].	diálogo competitivo (directiva 2004/18/CE, artículo 1(11) (c))
70.	Solicitud de propuestas sin negociación (artículos 29.3 y 47 [**hiperenlaces**])	Método de contratación cuya principal característica distintiva es la evaluación de las condiciones financieras de las ofertas tras haber concluido la evaluación de las características técnicas, de calidad y de rendimiento de las ofertas, por cuanto las ofertas se presentan a la entidad adjudicadora en dos sobres sellados separados. Para la explicación de los términos “método de contratación”, “evaluación” y “entidad adjudicadora”, véase ## 44, 27 y 62 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para la explicación del término “oferta”, véase # 83 <i>infra</i> [**hiperenlace**].	comparación de precios (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)
71.	Solicitud de cotizaciones (artículos 29.2 y 46 [**hiperenlaces**])	Método de contratación cuya principal característica distintiva es la presentación de una sola cotización por parte de los proveedores o contratistas en respuesta a la solicitud de cotizaciones de la entidad adjudicadora; la cotización no puede modificarse ni ser objeto de negociación (el método solo puede emplearse en relación con productos sencillos y de poca cuantía que están disponibles en el mercado). Para la explicación de los términos “método de contratación” y “entidad adjudicadora”, véase ## 44 y 62 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para la explicación del término “proveedor o contratista”, véase # 85 <i>infra</i> [**hiperenlace**].	comparación de precios (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
72.	Procedimientos de solicitud de propuestas (artículo 35 [**hiperenlace**])	Métodos de contratación que abarcan la solicitud de propuestas sin negociación, la solicitud de propuestas con diálogo y la solicitud de propuestas con negociación consecutiva (véase ## 70, 69 y 68 <i>supra</i>). Para la explicación del término “método de contratación”, véase # 44 <i>supra</i> [**hiperenlace**].	
73.	Procedimiento de licitación restringida (artículos 29.1 y 45 [**hiperenlaces**])	Método de contratación y una de las formas de licitación, cuya principal característica distintiva es la convocatoria directa. Para la explicación de los términos “método de contratación” y “convocatoria directa”, véase ## 44 y 19 <i>supra</i> [**hiperenlaces**].	• licitación selectiva (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículos I (q) y IX:4) • procedimientos restringidos (directiva 2004/18/CE, artículo 1(11) (b)) • licitación internacional limitada (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial) reapertura de la competencia (Nota explicativa de la UE sobre los acuerdos marco)¹¹
74.	Segunda etapa competitiva (artículo 2 [**hiperenlace**], definición e) iv), y capítulo VII [**hiperenlace**])	Etapa en los acuerdos marco cerrados con más de un proveedor o contratista y en los acuerdos marco abiertos en la que, al no haber sido posible determinar, al concluirse el acuerdo marco, algunas de las condiciones de la contratación, será preciso determinar o precisar esas condiciones mediante una competencia entre los proveedores o contratistas que sean partes en el acuerdo marco. Para la explicación de los términos “acuerdo marco cerrado”, “acuerdo marco abierto”, “contratación” y “acuerdo marco”, véase ## 10, 48, 58 y 31 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para la explicación del término “proveedor o contratista”, véase # 85 <i>infra</i> [**hiperenlace**].	
75.	Garantía de ejecución del contrato adjudicado (artículos 2, definición u), 17 y 39 [**hiperenlaces**])	Garantía contra el incumplimiento del contrato adjudicado por parte del proveedor o contratista con el que la entidad adjudicadora haya concertado ese contrato, presentada a la entidad adjudicadora por el proveedor o contratista en la forma, por el monto y con arreglo a cualesquiera otros requisitos (como los relativos a la índole de la garantía y al otorgante) especificados por la entidad adjudicadora en el pliego de condiciones. Para la explicación de los términos “contrato adjudicado” y “entidad adjudicadora”, véase ## 59 y 62 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para la explicación de los términos “proveedor o contratista” y “pliego de condiciones”, véase ## 85 y 80 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	garantía de cumplimiento (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)

¹¹ Documento CC/2005/03_rev 1 de 14 de julio de 2005. Disponible en la fecha de publicación del presente glosario en http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/explan-notes/classic-dir-framework_en.pdf.

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
76.	Servicios (artículo 39 [**hiperenlace**])	Servicios de índole intelectual y de consultoría y cualesquiera otros servicios que no estén abarcados en los términos “bienes” y “obras” <i>supra</i> (véase ## 35 y 15 [**hiperenlaces**]).	
77.	Contratación con un único proveedor o contratista (artículos 30.5 y 52 [**hiperenlaces**])	Método de contratación al que se recurre en último término y cuya principal característica distintiva es la ausencia de competencia, ya que la invitación a presentar una cotización o una propuesta se dirige a un único proveedor o contratista. Para la explicación del término “método de contratación”, véase # 44 <i>supra</i> [**hiperenlace**]. Para la explicación del término “proveedor o contratista”, véase # 85 <i>infra</i> [**hiperenlace**].	contratación directa (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)
78.	Políticas socioeconómicas (artículo 2 [**hiperenlace**], definición o), y artículo 25 [**hiperenlace**])	Definidas en la Ley Modelo como: “Consideraciones ecológicas, sociales y económicas que el reglamento de la contratación pública u otra norma aplicable de derecho interno autorice o exija que la entidad adjudicadora tenga en cuenta en el curso de la contratación.” Para la explicación de los términos “reglamento de la contratación pública” y “entidad adjudicadora”, véase ## 61 y 62 <i>supra</i> [**hiperenlaces**].	• trato especial y diferenciado para los países en desarrollo (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994, artículo V:1) • compensación (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo I:1) • obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones de protección y a las condiciones de trabajo; normas de gestión medioambiental (directiva 2004/18/CE, artículos 27 y 50) • sostenibilidad del proyecto; objetivos sociales del proyecto; preferencias para los bienes de fabricación nacional o para los contratistas nacionales (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)
79.	Convocatoria (artículo 2 [**hiperenlace**], definición p), artículos 6, 7, 18, y capítulo II, sección II [**hiperenlaces**])	Definida en la Ley Modelo como: “Toda invitación a licitar, a presentar ofertas o a participar en procedimientos de solicitud de propuestas o en subastas electrónicas inversas.” (véase # 41 <i>supra</i> [**hiperenlace**]).	• invitación a participar en relación con el contrato previsto (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994, artículo IX:1) • invitaciones a presentar ofertas, a participar en el diálogo o a negociar (directiva 2004/18/CE, artículo 40) • llamado a licitación (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
80.	Pliego de condiciones (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición q), y amplia utilización en toda la Ley Modelo)	Definido en la Ley Modelo como: “Documento emitido por la entidad adjudicadora, así como toda modificación de ese documento, en el que se fijen las condiciones de cada contrato adjudicable.” Para la explicación de los términos “entidad adjudicadora” y “contrato adjudicable”, véase ## 62 y 58 supra [**hiperenlaces**] .	• pliegos de condiciones (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo X:7) • pliego de condiciones y documento descriptivo (directiva 2004/18/CE, artículo 40(2)) • Documentos Estándar de Licitación (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)
81.	Moratoria (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición r), artículos 22, 25, 39, 47, 49, 53, 62, 66 y 67 [**hiperenlaces**])	Definida en la Ley Modelo como: “Plazo a partir del envío del aviso requerido por el párrafo 2 del artículo 22 de la presente Ley durante el cual la entidad adjudicadora no podrá aceptar la oferta ganadora y durante el cual los proveedores o contratistas podrán recurrir, en virtud del capítulo VIII de la presente Ley, contra la decisión así notificada.” Para la explicación del término “entidad adjudicadora”, véase # 62 supra [**hiperenlace**] . Para la explicación de los términos “oferta ganadora” y “proveedor o contratista”, véase ## 84 y 85 infra [**hiperenlaces**] .	• objeto del contrato (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994 y directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE)
82.	Objeto del contrato adjudicable (artículo 10 [**hiperenlace**] y amplia utilización en toda la Ley Modelo)	Necesidades de contratación -bienes, obras o servicios o cualquier combinación de estos adquiridos por la entidad adjudicadora en un proceso de contratación dado- tal como las haya descrito la entidad adjudicadora en el pliego de condiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Modelo [**hiperenlace**] . Para la explicación de los términos “bienes”, “obras” y “servicios”, véase ## 15, 35 y 76 supra [**hiperenlaces**] . Para la explicación de los términos “entidad adjudicadora”, “contratación” y “pliego de condiciones”, véase ## 62, 58 y 80 supra [**hiperenlaces**] .	objeto del contrato (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994 y directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE)
83.	Oferta (artículo 2 [**hiperenlace**] , definición s), y amplia utilización en toda la Ley Modelo)	Definida en la Ley Modelo como: “Una o más licitaciones, propuestas, ofertas, cotizaciones o pujas que se presenten, entendidas en sentido genérico o colectivo, y que incluyan, cuando el contexto lo requiera, ofertas iniciales o indicativas.”	• oferta (directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE) • oferta (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
84.	Oferta ganadora (artículos 9, 11, 17, 19, 22, 25, 31 y 62 [**hiperenlaces**])	La oferta que la entidad adjudicadora determine como tal durante la evaluación de las ofertas en función de los criterios y procedimientos de evaluación de las ofertas enunciados en el pliego de condiciones: • en los procedimientos de licitación, la oferta ganadora es: i) cuando el precio sea el único criterio de adjudicación de un contrato, aquella cuyo precio sea el más bajo; o ii) cuando existan otros criterios de adjudicación de un contrato, además del precio, aquella que sea calificada de más ventajosa (artículo 43.3 [**hiperenlace**]); • en los procedimientos de solicitud de cotizaciones, la oferta ganadora es la que presenta la cotización más baja que satisfaga las necesidades de la entidad adjudicadora que se fijen en la solicitud de cotizaciones (artículo 46.3 [**hiperenlace**]); • en los procedimientos de solicitud de propuestas sin negociación, la oferta ganadora es la que resulta mejor evaluada combinando el precio y los criterios distintos del precio que se especifiquen en la solicitud de propuestas (artículo 47.10 [**hiperenlace**]); • en los procedimientos de solicitud de propuestas con diálogo, la oferta ganadora es la que mejor responde a las necesidades de la entidad adjudicadora conforme se determine por el método y según los criterios de evaluación enunciados en la solicitud de propuestas (artículo 49.13 [**hiperenlace**]); • en los procedimientos de negociación competitiva, la oferta ganadora es la que mejor responde a las necesidades de la entidad adjudicadora (artículo 51.5 [**hiperenlace**]); y • en las subastas electrónicas inversas, la oferta ganadora es la que tiene el precio más bajo o la que sea la propuesta más ventajosa, determinada automáticamente por el sistema al clausurarse la subasta (artículo 2 [**hiperenlace**], definición d) y artículo 57.1 [**hiperenlace**]). Para la explicación de los términos “oferta”, “entidad adjudicadora”, “evaluación”, “pliego de condiciones”, y “oferta más ventajosa”, véase ## 83, 62, 27, 80 y 46 <i>supra</i> [**hiperenlaces**]. Para los métodos de contratación mencionados en esta columna en relación con esta definición, véase ## 49, 68 a 73, 12 y 24 <i>supra</i> y # 88 <i>infra</i> [**hiperenlaces**].	oferta del proveedor adjudicatario (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012)

#	Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)	Su definición o descripción	Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido
85.	Proveedor o contratista (artículo 2 [**hiperlance**] , definición t), y amplia utilización en toda la Ley Modelo)	Definido en la Ley Modelo como: “Según sea el caso, toda entidad comercial que pueda ser o sea ya parte en un proceso de contratación anunciado o abierto por la entidad adjudicadora.” Para la explicación del término “entidad adjudicadora”, véase ## 62 supra [**hiperlance**] .	• proveedor (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 2012, artículo I (t)) • contratista, proveedor y prestador de servicios (directiva 2004/18/CE, artículo 1(8)) • proveedores de bienes y servicios y contratistas (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial) precio cotizado (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)
86.	Precio de la oferta (artículos 39, 42, 43 y 48 [**hiperlances**])	El precio de la oferta tal como lo formulan y expresan los proveedores o contratistas en sus ofertas definitivas presentadas a la entidad adjudicadora y como lo anuncia la entidad adjudicadora en la apertura de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Modelo [**hiperlance**] ; cubre por regla general el costo del objeto del contrato adjudicable, a lo que se añade el costo de otros elementos constitutivos esenciales para suministrar el objeto del contrato adjudicable; el pliego de condiciones contiene instrucciones para los proveedores o contratistas sobre la manera de formular y expresar el precio de la oferta, incluida una indicación de si ese precio habrá de cubrir otros elementos distintos del costo en sí del objeto del contrato adjudicable, tales como cualesquiera gastos de transporte y de seguros, derechos de aduana e impuestos que sean aplicables (véase a este respecto el artículo 39 h) [**hiperlance**]). Para la explicación de los términos “proveedor o contratista”, “entidad adjudicadora”, “apertura de las ofertas”, “objeto del contrato adjudicable”, “elementos constitutivos” y “pliego de condiciones”, véase ## 85, 62, 50, 82, 14 y 80 supra [**hiperlances**] .	
87.	Garantía de la oferta (artículo 2 [**hiperlance**] , definición u))	Definida en la Ley Modelo como: “Garantía exigible de los proveedores o contratistas por la entidad adjudicadora y que habrá de serle entregada en garantía del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones enunciadas en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 17 de la presente Ley, garantía que podrá darse en forma de garantía bancaria, caución, carta de crédito contingente, cheque bancario, depósito en efectivo, pagaré o letra de cambio. Para evitar dudas, este concepto no será aplicable a ningún tipo de garantía de buen cumplimiento de un contrato.” Para la explicación de los términos “proveedor o contratista”, “entidad adjudicadora” y “garantía de buen cumplimiento de un contrato”, véase ## 85, 62 y 75 supra [**hiperlances**] .	garantía de seriedad (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)

#	<i>Término utilizado en la Ley Modelo (con referencias ilustrativas a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo)</i>	<i>Su definición o descripción</i>	<i>Otros términos utilizados en instrumentos internacionales que regulan la contratación pública y que tienen el mismo significado o un significado parecido</i>
88.	Licitación en dos etapas (artículos 30 1) y 48 [**hiperenlaces**])	Método de contratación y una de las formas de licitación, cuya principal característica distintiva es un proceso en dos etapas: • la primera etapa implica conversaciones entre la entidad adjudicadora y los proveedores o contratistas sobre diversos aspectos de sus ofertas iniciales, excluido el precio, para perfeccionar aspectos de la descripción del objeto de la contratación y para formularlos con la precisión que exige lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Modelo; y • la segunda etapa implica la presentación de ofertas definitivas y su respectivo precio en función de un conjunto de condiciones revisadas para la contratación, así como el examen y la evaluación de las ofertas definitivas y la adjudicación del contrato de adquisición. Para la explicación de los términos “método de contratación”, “entidad adjudicadora”, “proveedor o contratista”, “ofertas iniciales”, “descripción del objeto de la contratación”, “contratación”, “examen”, “evaluación” y “adjudicación del contrato de adquisición”, véase ## 44, 62, 85, 40, 18, 58, 29, 27 y 5 <i>supra</i> [**hiperenlaces**].	licitación en dos etapas (Normas sobre adquisiciones del Banco Mundial)

VII. LABOR FUTURA

A. Labor prevista y posible labor futura

(A/CN.9/774)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-5
A. Antecedentes	1-5
II. Resumen de las actividades actuales	6-9
A. Labor legislativa	6-7
B. Otras actividades	8-9
III. Resumen de las actividades previstas y las actividades posibles a partir de julio de 2013	10-14
A. Labor legislativa	10-11
1. Futura labor prevista	10
2. Futura labor posible	11
B. Actividades de apoyo a la aprobación y el uso de textos de la CNUDMI	12-14
IV. Asignación de recursos y establecimiento de prioridades	15-47
A. Nivel de actividad y necesidad de establecer prioridades o modificar los métodos de trabajo	15-18
B. Establecimiento de prioridades con respecto a las esferas temáticas	19-33
C. Posible necesidad de modificar los métodos de trabajo	34-37
D. Establecimiento de prioridades en el marco del programa de trabajo general de la CNUDMI	38-42
E. Cuestiones conexas	43-47
1. Apoyo de los grupos de trabajo y la Comisión a las actividades encaminadas a promover la aprobación y el uso de textos de la CNUDMI	43-44
2. Publicación de los documentos en todos los idiomas oficiales de la CNUDMI	45-47

I. Introducción

A. Antecedentes

1. En su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión pidió a la Secretaría que preparara una nota sobre la planificación estratégica para su siguiente período de sesiones (A/66/17, párr. 343).
2. En su 45º período de sesiones, se presentó a la Comisión una nota de la Secretaría, preparada en respuesta a esa solicitud, que llevaba por título “Un rumbo estratégico para la CNUDMI” (A/CN.9/752 y Add.1, aquí denominados indistintamente “documento sobre el rumbo estratégico”). La Comisión decidió examinar el rumbo estratégico de la CNUDMI y dar más orientación al respecto en su 46º período de sesiones y pidió a la Secretaría que reservara suficiente tiempo para mantener deliberaciones a fondo en ese período de sesiones (A/67/17, párr. 231).
3. En el documento sobre el rumbo estratégico se exponían determinados factores para ayudar a la Comisión cuando examinara su posible labor futura, particularmente a la hora de elegir entre varios temas si no disponía de recursos suficientes para ocuparse de todos los temas actuales y posibles temas futuros (A/CN.9/752, párrs. 20 y 21). En el presente documento figura información detallada sobre la labor actual y la posible labor futura; en vista de que la Comisión tal vez considere que los recursos de la CNUDMI han pasado a ser insuficientes (véase lo que sigue en la sección IV), el documento se ha preparado para ayudarla tanto a examinar su futura labor en el actual 46º período de sesiones como a examinar el documento sobre el rumbo estratégico (A/CN.9/752 y Add.1).
4. El presente documento abarca todas las esferas principales de la labor de la CNUDMI: los textos legislativos previstos y los posibles textos legislativos futuros, la asistencia técnica para la reforma legislativa, la promoción de una interpretación y aplicación uniformes de los textos de la CNUDMI, la situación actual y la promoción de esos textos, la coordinación y cooperación con otras organizaciones que operan en su ámbito de acción y la promoción del estado de derecho. Con ello se pretende que la Comisión pueda examinar la manera en que un mandato cualquiera encomendado en relación con una actividad cualquiera correspondiente a un tema cualquiera afectará a las demás actividades y temas de la CNUDMI.
5. Al examinar estas cuestiones la Comisión tal vez desee tener en cuenta los siguientes documentos. Los documentos de antecedentes presentados a la Comisión en su 45º período de sesiones (disponibles en www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/45th.html) son:

A/CN.9/752 y Add.1 Un rumbo estratégico para la CNUDMI. Nota de la Secretaría; y

A/67/17 Informe sobre el 45º período de sesiones de la Comisión.

Los documentos correspondientes al actual período de sesiones de la Comisión (disponibles en <http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/46th.html>) son:

A/CN.9/760 y A/CN.9/765 Informes del Grupo de Trabajo II sobre la labor de sus períodos de sesiones 57° y 58°;

A/CN.9/762 y A/CN.9/769 Informes del Grupo de Trabajo III sobre la labor de sus períodos de sesiones 26° y 27°;

A/CN.9/761 y A/CN.9/768 Informes del Grupo de Trabajo IV sobre la labor de sus períodos de sesiones 46° y 47°;

A/CN.9/763 y A/CN.9/766 Informes del Grupo de Trabajo V sobre la labor de sus períodos de sesiones 42° y 43°;

A/CN.9/764 y A/CN.9/767 Informes del Grupo de Trabajo VI sobre la labor de sus períodos de sesiones 22° y 23°;

A/CN.9/773 Situación actual de las convenciones y leyes modelo. Nota de la Secretaría;

A/CN.9/775 Nota de la Secretaría sobre las actividades de asistencia técnica realizadas desde el 45° período de sesiones de la Comisión y sobre los recursos de asistencia técnica, entre ellos las publicaciones de la CNUDMI, su sitio web y un estudio de las actividades realizadas por el Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico desde el 45° período de sesiones de la Comisión;

A/CN.9/776 Breve exposición de las actividades que ha venido realizando la Secretaría desde el 45° período de sesiones de la Comisión para garantizar la coordinación con la labor de otras organizaciones que se ocupan del derecho mercantil internacional. Nota de la Secretaría;

A/CN.9/777 Estado y evolución de la Jurisprudencia de los Tribunales sobre Textos de la CNUDMI. Nota de la Secretaría (incluye información actualizada sobre las actividades en curso relativas a los compendios);

A/CN.9/779 Informe de un coloquio sobre la colaboración entre el sector público y el sector privado;

A/CN.9/780 Creación de un entorno jurídico favorable a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Nota de la Secretaría;

A/CN.9/785 Posible labor futura en materia de solución de controversias. Nota de la Secretaría;

A/CN.9/788 Reunión sobre el fraude comercial. Nota de la Secretaría.

II. Resumen de las actividades actuales

A. Labor legislativa

6. En el cuadro que sigue se indican las actividades legislativas actualmente y en curso y las fechas de terminación previstas.

7. Como se observa en el cuadro, en el 46° período de sesiones de la Comisión se someterán a su aprobación proyectos de texto sobre arbitraje, insolvencia y garantías reales. En consecuencia, los grupos de trabajo correspondientes (II, V y VI) estarán en condiciones de emprender la futura labor, parte de la cual ya ha encomendado la Comisión (como se explica a continuación en la sección III, párrs. 10 a 14). En abril de 2012 el Grupo de Trabajo I terminó de preparar la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública y la correspondiente Guía para la incorporación al derecho interno. Este Grupo de Trabajo no se ha reunido desde el 45° período de sesiones de la Comisión, celebrado en 2012, por lo que está en condiciones de asumir futuras labores. Los Grupos de Trabajo III y IV se ocupan de labores en curso.

Cuadro 1

Actividades legislativas actuales y en curso

<i>Tema</i>	<i>Informes de referencia</i>	<i>Fecha de terminación prevista</i>
<i>Arbitraje (Grupo de Trabajo II)</i>		
i) Preparación de una norma jurídica acerca de la transparencia en los arbitrajes entablados con inversionistas en el marco de un tratado	A/CN.9/760 y A/CN.9/765	2013
ii) Aplicabilidad del reglamento sobre la transparencia de la CNUDMI a la solución de controversias surgidas en el marco de tratados de inversión ya existentes (proyecto de texto de recomendación y convención)		2013
Preparación de una Guía sobre la Convención de Nueva York de 1958	n/d – preparado por la Secretaría	Trozos escogidos con fines de examen, 2013; terminación en 2014
<i>Solución de controversias en línea (Grupo de Trabajo III)</i>		
Preparación de una norma jurídica que regule la solución en línea de controversias surgidas en el marco de operaciones transfronterizas de comercio electrónico	A/CN.9/762 y A/CN.9/769	Estimación: 2014 o más tarde
<i>Comercio electrónico (Grupo de Trabajo IV)</i>		
Documentos transmisibles electrónicos	A/CN.9/761 y A/CN.9/768	Estimación: 2015 o más tarde
<i>Insolvencia (Grupo de Trabajo V)</i>		
i) Revisiones de la Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza	A/CN.9/763 y A/CN.9/766	2013
ii) Obligaciones de los directores de empresas en el período cercano a la insolvencia		2013
iii) Actualización de <i>La Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza: La Perspectiva Judicial</i>		2013

<i>Tema</i>	<i>Informes de referencia</i>	<i>Fecha de terminación prevista</i>
<i>Garantías reales (Grupo de Trabajo VI)</i>		
i) Proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales	A/CN.9/764 y A/CN.9/767	2013
ii) Proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas ¹		Se desconoce

B. Otras actividades

8. Las principales esferas de actividad de la CNUDMI distintas de la elaboración de legislación forman parte de su mandato de apoyo a la aprobación y el uso de textos de la CNUDMI. Las principales actividades al respecto son la cooperación y la asistencia técnica, que abarcan la labor de fomento de la aprobación de un texto y su aplicación e interpretación, y la coordinación de la labor en la esfera del derecho mercantil internacional. Como se observa en el documento sobre el rumbo estratégico, la auténtica armonización exige tener en cuenta todas esas esferas, además de la actividad legislativa, para cada texto que apruebe la CNUDMI (véase A/CN.9/752, párr. 3).

9. En el 46º período de sesiones de la Comisión se dispondrá de los siguientes informes en que se describen las actividades actuales de la CNUDMI en estos ámbitos:

A/CN.9/772 Bibliografía de obras recientemente publicadas relativas a la labor de la CNUDMI;

A/CN.9/775 Asistencia técnica para la reforma legislativa y recursos de asistencia técnica, entre ellos las publicaciones de la CNUDMI, el sitio web de la CNUDMI y la presencia regional de la CNUDMI: estudio de las actividades llevadas a cabo por el Centro Regional para Asia y el Pacífico de la CNUDMI;

A/CN.9/773 Situación y promoción de textos jurídicos de la CNUDMI (situación de los tratados y de las leyes modelo dimanantes de la labor de la CNUDMI y situación de la Convención de Nueva York);

A/CN.9/776 Coordinación y cooperación: i) breve exposición de las actividades realizadas por la Secretaría; ii) informes de otras organizaciones internacionales;

A/CN.9/777 Fomento de los modos necesarios para asegurar una interpretación y aplicación uniformes de los textos jurídicos de la CNUDMI: i) Jurisprudencia de los Tribunales sobre Textos de la CNUDMI, ii) Compendios de jurisprudencia relativa a textos jurídicos de la CNUDMI;

¹ En su 23º período de sesiones (2013), el Grupo de Trabajo mantuvo un intercambio general de opiniones sobre el proyecto de Ley Modelo, en particular sobre el alcance del mandato del Grupo de Trabajo en lo que a dicho proyecto se refería.

Informe verbal Función que desempeña la CNUDMI en el fomento del estado de derecho a nivel nacional e internacional

III. Resumen de las actividades previstas y las actividades posibles a partir de julio de 2013

A. Labor legislativa

1. Futura labor prevista

10. La Comisión ha estudiado anteriormente propuestas de futura labor legislativa sobre los siguientes temas y ha encomendado a un grupo de trabajo que inicie la labor al respecto en un futuro²:

a) *Arbitraje*: véase la Nota de la Secretaría sobre la posible labor futura en materia de solución de controversias (A/CN.9/785), que examina i) la arbitrabilidad, tema mantenido desde 2006 por el Grupo de Trabajo II en su futuro programa de trabajo (A/62/17, párr. 177)³, y ii) la revisión de las Notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral, de 1996. La Comisión convino en decidir en un futuro período de sesiones si el proyecto de revisión de las Notas debía ser examinado por el Grupo de Trabajo antes de que lo examinase la Comisión o si la labor correspondía a la Secretaría (A/67/17, párr. 70);

b) *Insolvencia*: el actual mandato del Grupo de Trabajo, además de incluir la formulación de orientaciones sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses, comprende la posible preparación de un texto legislativo (como una ley modelo, una convención o convenio o disposiciones de una ley de insolvencia nacional) en el que se regulen determinadas cuestiones internacionales, como la jurisdicción, el acceso y el reconocimiento. El Grupo de Trabajo V ha recomendado que la Comisión confirmara su opinión en el sentido de que el alcance del mandato del Grupo en la materia aprobado originalmente incluía la cuestión del centro de los principales intereses en el contexto de los grupos de sociedades (A/CN.9/763, párr. 13). El Grupo de Trabajo V convino en que se examinara esa cuestión después de introducir las actuales revisiones propuestas de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza en relación con el centro de los principales intereses de deudores individuales (A/CN.9/763, párr. 14). El Grupo de Trabajo también convino en que se examinaran las obligaciones de los directores en el contexto de la insolvencia de los grupos de sociedades (A/CN.9/763, párr. 92, y A/CN.9/766, párr. 104);

c) *Garantías reales*: la Comisión encomendó al Grupo de Trabajo VI el mandato de preparar una ley modelo sobre las operaciones garantizadas, empezando por la elaboración de un texto que fuera sencillo, breve y conciso (A/67/17,

² Los temas que la Comisión ha estudiado a grandes rasgos, pero ha acordado retomar tras el examen de otras propuestas o propuestas revisadas que se le presenten, figuran en la siguiente subsección como propuestas de posible labor futura.

³ Véanse también los informes posteriores de la Comisión A/63/17 y Corr.1, párr. 316; A/64/17, párr. 299; y A/66/17, párr. 203.

párr. 105). En el informe de ese Grupo de Trabajo figura un intercambio de opiniones sobre ese mandato y el alcance de la ley modelo que ha de elaborarse (A/CN.9/767, párrs. 63 y 64)⁴.

2. Futura labor posible

11. La Comisión tiene ante sí propuestas de futuras labores legislativas posibles en las siguientes esferas temáticas (enumeradas por orden alfabético):

a) *Arbitraje*: véase la nota de la Secretaría sobre la posible labor futura en materia de solución de controversias comerciales (A/CN.9/785), que hace referencia a la labor determinada en consultas celebradas por la Secretaría: se consideró que cada vez cobraba más importancia la cuestión de los procedimientos paralelos en la esfera del arbitraje en materia de inversiones;

b) *Comercio electrónico*: la Comisión había convenido antes en que la labor relativa a los documentos transmisibles electrónicos podía abarcar aspectos de otros asuntos, como la gestión de los datos de identificación personal, el comercio electrónico por conducto de dispositivos móviles y los sistemas electrónicos de ventanilla única. Sin embargo, la Comisión no ha encomendado a ningún grupo de trabajo que se encargue de estos temas, excepto en el marco de la actual labor sobre documentos transmisibles electrónicos (A/66/17, párrs. 235 y 239);

c) *Contratación pública y temas conexos, incluida la colaboración entre los sectores público y privado*: en su 45º período de sesiones, la Comisión convino en que debía prepararse un glosario de términos empleados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública, así como propuestas de temas relativos a los reglamentos en materia de contratación para prestar apoyo a la Ley Modelo. La Comisión tendrá ante sí con fines de examen proyectos de documento sobre estos temas (A/CN.9/771 y A/CN.9/772, respectivamente).

La Comisión también convino en estudiar la posibilidad de preparar nuevos documentos orientativos sobre varios temas para prestar apoyo al funcionamiento y la aplicación de la Ley Modelo y encargó a la Secretaría que realizase un estudio sobre temas que merecieran documentos orientativos de ese tipo. La Comisión también encargó a la Secretaría que estudiase opciones en cuanto a publicar y divulgar los distintos recursos y los documentos en sí (A/67/17, párrs. 109, 110 y 114). Por lo que se refiere a varios de esos temas (suspensión, inhabilitación profesional y rectificación de la causa de inhabilitación, códigos de conducta, interacción entre los proveedores o contratistas y las entidades adjudicadoras y controles internos), las consultas indicaban que tal vez fueran necesarias más labores legislativas con respecto a algunos o a todos ellos. En cuanto a los demás temas, las consultas indicaban que no estaba justificado emprender nuevas actividades legislativas, si bien, en su debido momento, se presentaría material nuevo a la Secretaría.

En cuanto a la colaboración entre el sector público y el sector privado, la Comisión también tendrá ante sí con fines de examen las recomendaciones formuladas en un coloquio celebrado en Viena los días 2 y 3 de mayo de 2013, en atención a una propuesta de la Comisión, presentada en su 45º período de sesiones

⁴ Véase la nota de pie de página 1.

(*ibid.*, párr. 120), de estudiar la futura labor posible en materia de colaboración entre los sectores público y privado (A/CN.9/779);

d) *Derecho contractual internacional*: En su 45° período de sesiones, celebrado en 2012, la Comisión examinó la conveniencia de ocuparse del derecho contractual internacional a raíz de una propuesta formulada por Suiza (A/CN.9/758). Se juzgó predominante la opinión de solicitar a la Secretaría que organizara simposios y otras reuniones, entre ellas encuentros a nivel regional, en estrecha colaboración con el UNIDROIT, con miras a reunir más información que sirviera de ayuda a la Comisión para determinar la conveniencia y viabilidad de emprender en un ulterior período de sesiones una labor futura en materia de derecho contractual general. En su 46° período de sesiones, la Secretaría presentará a la Comisión un informe verbal sobre el tema;

e) *Fraude comercial*: la CNUDMI ha examinado la cuestión del fraude comercial internacional en varios de sus períodos de sesiones, empezando por el 35°, celebrado en 2002 (A/57/17, párrs. 279 a 290; véanse también las ulteriores deliberaciones mencionadas en el párr. 75 del programa del 46° período de sesiones de la Comisión). En el presente período de sesiones, la Comisión tendrá a su disposición una nota sobre el fraude comercial (A/CN.9/788) en la que se expondrán las conclusiones de una reunión oficiosa organizada en Viena por la Secretaría los días 29 y 30 de abril de 2013;

f) *Garantías reales*: la Comisión convino en que se mantuvieran en el futuro programa de trabajo del Grupo de Trabajo VI los temas de las garantías reales sobre valores no depositados en poder de intermediarios, entendidas como garantías distintas de las acreditadas en una cuenta de valores, los derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía y las cuestiones concretas que se plantearan en el contexto de la concesión de licencias de propiedad intelectual (A/67/17, párrs. 105, 268 y 273), de conformidad con lo recomendado antes en el Coloquio Internacional de 2010 sobre Garantías Reales (http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_security.html);

g) *Insolvencia*: además de los temas relacionados con el resto de su actual mandato, se mencionaron los siguientes temas objeto de una posible labor futura en el 43° período de sesiones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/766, párr. 109), reconociendo que más adelante habría que solicitar a la Comisión un nuevo mandato al respecto: normas de derecho internacional privado aplicables a procedimientos de insolvencia, especialmente en lo referente a grupos de sociedades; la eficacia, en el contexto de la crisis financiera mundial, de los actuales instrumentos, en particular de las disposiciones de la Guía legislativa sobre el régimen de la insolvencia relativas a los contratos financieros; la pertinencia de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza para la resolución de las instituciones financieras; y el cumplimiento obligatorio de derechos sustantivos y reclamaciones en un contexto de insolvencia transfronteriza;

h) *Microfinanzas/creación de un entorno jurídico favorable a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas*: en su 45° período de sesiones, la Comisión convino en que se celebraran uno o más coloquios sobre microfinanzas y cuestiones conexas centrados en temas relacionados con la creación de un entorno jurídico favorable a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. En su 46° período de sesiones, la Comisión tendrá a su disposición una nota

(A/CN.9/780) en la que se expondrán las principales constataciones del coloquio organizado por la Secretaría en Viena del 16 al 18 de enero de 2013, así como recomendaciones que habrá de examinar. La Comisión también escuchará un informe verbal sobre las respuestas de los Estados a un cuestionario (distribuido en 2011-2012) relativo a su experiencia en cuanto al establecimiento de un marco legislativo y reglamentario de las microfinanzas;

i) *Solución de controversias en línea*: La futura labor planteada en el 44º período de sesiones de la Comisión incluye directrices y requisitos mínimos para proveedores de soluciones de controversias en línea y terceros neutrales; principios jurídicos sustantivos para resolver controversias; y un mecanismo para la ejecución transfronteriza (A/66/17, párrs. 213 y 214).

Cuadro 2

Resumen de las actividades legislativas previstas y las posibles actividades futuras

<i>Tema</i>	<i>Propuesta</i>	<i>Labor prevista o posible labor futura</i>	<i>Otras esferas temáticas pertinentes</i>
Arbitraje	- Arbitrabilidad; revisión de las <i>Notas sobre la organización del proceso arbitral</i> - Procedimientos múltiples y paralelos en la esfera del arbitraje en materia de inversiones; juntas de solución de controversias	Prevista Posible	—
Fraude comercial	Examen de las conclusiones de la reunión oficiosa	—	
Comercio electrónico	Gestión de la identidad; ventanillas únicas; comercio móvil	Posible	—
Insolvencia	Centro de los principales intereses en el contexto de los grupos de empresas (incluidos aspectos internacionales como la jurisdicción, el acceso y el reconocimiento); obligaciones de los directores en el contexto de grupos	Prevista	
Derecho contractual internacional	Propuesta amplia sobre derecho contractual internacional	Posible	—
Microfinanzas/ Creación de un entorno jurídico favorable a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas	Aspectos jurídicos de la creación de un entorno favorable a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, como la estructura social, la solución de controversias, las transferencias electrónicas, el acceso al crédito y la insolvencia	Posible	Arbitraje/conciliación, insolvencia, garantías reales, comercio electrónico
Solución de controversias en línea	Directrices y cuestiones afines; principios jurídicos sustantivos; mecanismo de cumplimiento transfronterizo	Posible	Arbitraje/conciliación, comercio electrónico
Contratación	Cuestiones relativas a las sanciones	Posible	Arbitraje/conciliación

<i>Tema</i>	<i>Propuesta</i>	<i>Labor prevista o posible labor futura</i>	<i>Otras esferas temáticas pertinentes</i>
pública			
Colaboración entre el sector público y el sector privado	Elaboración de una ley modelo o guía legislativa ⁵	Posible	Arbitraje/conciliación
Garantías reales ⁶	- Preparación de una ley modelo sobre las operaciones garantizadas	Prevista	Insolvencia
	- Valores no depositados en poder de intermediarios; derechos de las partes; propiedad intelectual	Posible	

B. Actividades de apoyo a la aprobación y el uso de textos de la CNUDMI

12. Los informes de las actividades de apoyo a la aprobación y el uso de textos de la CNUDMI (con inclusión de la asistencia técnica, el fomento de los modos necesarios para asegurar una interpretación y aplicación uniformes de los textos de la CNUDMI, la determinación de la situación de los textos de la CNUDMI y la correspondiente labor de promoción, la coordinación y la cooperación y la promoción del estado de derecho en los planos nacional e internacional) figuran en los documentos A/CN.9/772, A/CN.9/773, A/CN.9/775, A/CN.9/776 y A/CN.9/777; otras actividades se comunicarán verbalmente a la Comisión⁷. Está previsto que estas actividades prosigan el año que viene en un nivel aproximadamente idéntico al registrado durante el año hasta julio de 2013.

13. Sin embargo, como se señalaba varias veces en esos documentos, la demanda de esas actividades supera con creces los recursos de que dispone la Secretaría para atenderla, incluso con los recursos adicionales aportados por la oficina regional de la CNUDMI en Incheon.

14. A continuación se examinan las consecuencias para la planificación de la futura labor en la CNUDMI y su rumbo estratégico.

IV. Asignación de recursos y establecimiento de prioridades

A. Nivel de actividad y necesidad de establecer prioridades o modificar los métodos de trabajo

15. En su 45º período de sesiones, la Comisión señaló que, "... tal como se desprende del análisis anterior, la CNUDMI, con los recursos actualmente

⁵ El Coloquio se celebrará con posterioridad a la fecha del presente informe. En vista de que la preparación de un texto jurídico sobre la colaboración entre el sector público y el sector privado es uno de los temas que se examinarán en el Coloquio, se menciona aquí en aras de la exhaustividad; deberán examinarse las recomendaciones que figuren en el informe del Coloquio (A/CN.9/779).

⁶ Véase la nota de pie de página 1.

⁷ Por lo que se refiere a las actividades de coordinación en materia de garantías reales, véase el programa provisional A/CN.9/759, párr. 18.

disponibles, no puede seguir generando textos jurídicos al ritmo actual y contribuir en el grado necesario a la aplicación y utilización de todos los textos de la CNUDMI” (A/CN.9/752/Add.1, párr. 25).

16. En el plano legislativo, en el párrafo 7 y el cuadro 1 figuran las actividades en curso de los grupos de trabajo, incluidas las que concluirán en el 46º período de sesiones de la Comisión y las que se seguirán llevando a cabo; el Grupo de Trabajo I carece actualmente de mandato legislativo. Por lo tanto, la Comisión dispone de mucha flexibilidad para determinar su futuro programa de trabajo legislativo. En los párrafos 10 y 11 y en el cuadro 2 se exponían las propuestas de labor futura presentadas; en la última columna del cuadro se indican los aspectos de las propuestas que pueden guardar relación con otra esfera temática. En los informes verbales a la Comisión y en los siguientes documentos pueden consultarse más detalles sobre algunas de las propuestas: A/CN.9/785 (arbitraje y conciliación); A/CN.9/763, párrs. 13 y 14, y A/CN.9/766, párrs. 103 y 104 (insolvencia); A/CN.9/780, párrs. 49 a 55 (microfinanzas/creación de un entorno jurídico favorable a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas); A/66/17, párrs. 213 y 214 (solución de controversias en línea); A/CN.9/779 (colaboración entre el sector público y el sector privado); y A/CN.9/788 (fraude comercial).

17. Es evidente que seis grupos de trabajo no pueden ocuparse simultáneamente de todas estas actividades si se mantienen los actuales métodos de trabajo de la CNUDMI (descritos en A/CN.9/752, párr. 5 y sección B), a menos que se pongan en práctica algunas de las sugerencias propuestas en el documento sobre el rumbo estratégico (A/CN.9/752, párrs. 34 y 35 y 37 a 40), como a) la asignación de más de un tema a cada grupo de trabajo y b) un mayor hincapié en las negociaciones oficiosas frente a las oficiales al elaborar los textos, para que un grupo de trabajo pueda ocuparse de más de un tema durante las dos semanas anuales que tiene asignadas para celebrar conferencias.

18. Dicho de otro modo, la actividad legislativa de la CNUDMI ha llegado a un punto en que es necesario establecer prioridades entre las distintas esferas temáticas o modificar sus métodos de trabajo, incluso antes de plantearse la asignación de recursos correspondientes a las actividades legislativas y de otro tipo (cuestión que se aborda en la sección D del presente documento, párrs. 38 a 42).

B. Establecimiento de prioridades con respecto a las esferas temáticas

19. El establecimiento de prioridades con respecto a las esferas temáticas fue objeto de deliberaciones en el primer período de sesiones de la Comisión, celebrado en 1968, en el que se determinó que era la manera apropiada de seleccionar temas para su labor (A/7216, párr. 39). En ese primer período de sesiones, la Comisión también tuvo ante sí un informe sobre el desarrollo progresivo del derecho mercantil internacional, presentado por el Secretario General a la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones, el mismo período de sesiones en que se estableció la CNUDMI (A/6396).

20. En el informe el Secretario General afirmaba que “al estudiar las cuestiones que se prestan a armonización y unificación es preciso hacer tres observaciones generales. En primer lugar, ... la armonización ... se logra con más facilidad en

las ramas técnicas del derecho que en las materias íntimamente vinculadas con las tradiciones nacionales y los principios fundamentales del derecho interno” (A/6396, párr. 203). Se citaron como ejemplos de ramas técnicas del derecho el transporte, la banca internacional y el arbitraje.

21. La segunda observación era que “el proceso de unificación no siempre es aconsejable de por sí: sólo es apetecible cuando hay una necesidad económica y las medidas unificadoras han de redundar en provecho del desarrollo del comercio internacional” (A/6396, párr. 204).

22. La tercera observación era que, “además de sus efectos directos, las medidas unificadoras tienden a producir lo que se ha llamado un efecto de ‘irradiación’. Ello ocurre cuando, por ejemplo, un Estado que no es parte en una convención internacional decide aplicar el principio en que la misma se basa, o cuando una técnica de unificación empleada en un instrumento internacional se incorpora ulteriormente a otro” (A/6396, párr. 205).

23. En su primer período de sesiones, la Comisión decidió que seleccionaría varios temas sustantivos para incluirlos en su futuro programa de trabajo y escogería determinados temas con carácter prioritario (A/7216, párr. 34). En el informe de ese período de sesiones no se describen detalladamente las deliberaciones en torno al establecimiento de prioridades con respecto a los distintos temas, pero las conclusiones reflejan los asuntos y temas sugeridos que aparecían en el informe del Secretario General (véase, también, el documento sobre el rumbo estratégico, A/CN.9/752, párr. 6). La Comisión también declaró en su primer período de sesiones que se centraría en temas a corto plazo, en lugar de ocuparse de todos los temas propuestos en el período de sesiones, indicando la prioridad de cada uno (A/7216, párr. 34).

24. Aunque el derecho mercantil internacional privado ha evolucionado mucho desde entonces, la Comisión puede entender que esas observaciones deben seguir orientando su selección de temas.

25. La primera observación explica por qué la CNUDMI no se ha ocupado de asuntos como la reglamentación del derecho empresarial y tributario. La Comisión se ha centrado más bien en los temas expuestos antes en el párrafo 20, además de otros, como la compraventa internacional de mercaderías, el comercio electrónico, la insolvencia y la solución de controversias en línea, descritos con mayor detalle en el documento sobre el rumbo estratégico (A/CN.9/752, párrs. 6 y 7).

26. La segunda observación explica, entre otras cosas, por qué la CNUDMI se ha ocupado de algunos temas que guardan una relación más estrecha con las tradiciones nacionales, como el derecho de la contratación pública y el régimen de la insolvencia. El motivo es que esos temas tienen un posible efecto beneficioso en el desarrollo del comercio internacional, en lugar de en el desarrollo del marco jurídico y reglamentario de un solo país. (En el caso de la contratación pública, la OCDE estima que el valor de mercado total se acerca al 13% del PIB en los países de la OCDE y es superior en otras zonas; la Unión Europea indica que el comercio internacional, incluso dentro de sus fronteras, es inferior al 5% del valor de los contratos, y muchos sistemas oponían numerosos obstáculos a la participación extranjera antes de que la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y la CNUDMI publicaran textos para la eliminación de dichos obstáculos.)

27. La Comisión sabrá que la tercera observación ha quedado demostrada en la práctica. Son ejemplos de ello el hecho de que los seis Estados miembros de la Comisión integrantes de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) hayan incorporado a su derecho interno los aspectos centrales del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo (Reglas de Rotterdam) sin ratificar el Convenio; que la Organización para la Armonización de la Legislación Empresarial en África utilice la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CIM) como ley regional sin haber ratificado la Convención; y, en el contexto de la actualización de las leyes sobre comercio electrónico, que varios Estados incluyan disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales sin haber ratificado la Convención, así como que hayan incorporado a su derecho interno una ley modelo regional basada en la Convención.

28. En el documento sobre el rumbo estratégico se señala que, para determinar las prioridades del programa de trabajo de la CNUDMI, debe tenerse en cuenta no solo su alcance actual y posible (es decir, los recursos disponibles para sus actividades), sino también la función y la pertinencia de la CNUDMI en el marco de las Naciones Unidas y en el contexto del comercio y las relaciones comerciales internacionales (A/CN.9/752/Add.1, párr. 24). En el mismo documento se señala a continuación que “la función y la pertinencia de la CNUDMI pueden evaluarse en función de la labor y de las prioridades de las Naciones Unidas, de las comunidades de donantes y de las prioridades de los diversos gobiernos. Hay elementos clave, como la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (2005), e importantes cuestiones de gran relieve internacional, como el programa contra la corrupción, el desplome de los mercados financieros del mundo en 2008 y las situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, que determinarán las prioridades de esos órganos” (*ibid.*).

29. Otro principio que la Comisión tal vez desee aplicar al establecer prioridades en cuanto a las esferas temáticas es la medida en que la labor centrada en un tema cualquiera seleccionado por la Comisión a) coincidiría con las prioridades de estos órganos y de los Estados miembros y b) permitiría adoptar un enfoque de simbiosis con las actividades de estos organismos indicadas en las notas de la Secretaría sobre las actividades de asistencia técnica y las actividades orientadas a garantizar la coordinación con otras organizaciones que se ocupan del derecho mercantil internacional llevadas a cabo desde el 45º período de sesiones de la Comisión (A/CN.9/775 y A/CN.9/776, respectivamente).

30. En consecuencia, la Comisión tal vez desee tener en cuenta las tres observaciones y lo señalado en el párrafo anterior al seleccionar entre las propuestas del cuadro 2 con miras a su futura actividad legislativa. El material mencionado en el párrafo 16, en el que se describen las propuestas con mayor detenimiento, puede ayudar a la Comisión a evaluar cómo encajan con su mandato y con las prioridades de las comunidades de donantes y los gobiernos nacionales. De decidir la Comisión, por ejemplo, que un tema es de importancia para el desarrollo, pero no se corresponde con su mandato relativo al derecho mercantil internacional, también podría recomendarlo a otro órgano dedicado a la reforma legislativa para que lo incorporara en su programa de trabajo.

31. A ese respecto, la Comisión tal vez desee también contrastar las propuestas de los grupos de trabajo para emprender nuevas labores en sus esferas temáticas con las opiniones de los Estados miembros en un plano más estratégico.

32. Por lo que se refiere al período durante el cual tiene previsto emprender su futura labor, la Comisión tal vez desee consultar con miembros de los grupos de trabajo pertinentes y observadores en dichos grupos, así como con la Secretaría, en relación con el calendario probable de la actividad legislativa prevista y la posible actividad legislativa futura, a fin de garantizar que su planificación coincide con el período de vigencia de un texto (véase al respecto el documento sobre el rumbo estratégico, párrs. 6 a 62). Además, la Comisión tal vez entienda que algunas de las propuestas de labor futura, ya sea posible o prevista, deberían anteponerse a otras, es decir, que deben establecerse prioridades en cuanto a la importancia de los temas y el calendario para tratarlos.

33. La Comisión tal vez desee también examinar si las prioridades establecidas en cuanto a los temas de la actividad legislativa deben coincidir con las actividades de apoyo a la aprobación y el uso de textos de la CNUDMI y su programa de trabajo general o si en ese contexto han de tenerse en cuenta otras consideraciones. En los párrafos 39 y 41 del presente documento se examinan algunos aspectos del posible alcance de las actividades centradas en la aprobación y el uso de textos de la CNUDMI.

C. Posible necesidad de modificar los métodos de trabajo

34. La Comisión tal vez desee tener presentes las cuestiones planteadas en el documento sobre el rumbo estratégico con respecto a los métodos de trabajo, en particular por lo que se refiere al número anual de períodos de sesiones de los grupos de trabajo, la documentación y los métodos de trabajo (párrs. 34 a 40). Resumiendo, en esa sección se señalaba la importancia de la metodología de la labor de la Comisión basada en el consenso a efectos de garantizar textos aceptables, si bien se observaba que la prestación de servicios a seis grupos de trabajo obligaba a estirar al máximo los recursos de la Secretaría; también se indicaba que era importante emprender parte de la labor oficiosamente y reducir la documentación.

35. Una opción antes señalada consistiría en que cada grupo de trabajo se ocupara a la vez de más de un tema: podría reservarse una reunión anual a un solo tema y una segunda reunión a otro, con lo cual se respetaría el tiempo de conferencias asignado a los períodos de sesiones de los grupos de trabajo. Este enfoque facilitaría la realización de actividades legislativas con respecto a más de seis temas a la vez. Sin embargo, la Comisión tal vez entienda que ese enfoque obligaría a estirar los recursos de la Secretaría más allá de lo razonable.

36. Otra opción consistiría en aumentar la proporción de negociaciones oficiosas frente a las oficiales y preparar algunos textos al margen de la estructura de los grupos de trabajo para presentarlos directamente a la Comisión (algo que ya se ha hecho antes, como se indica en el documento sobre el rumbo estratégico, párr. 33). De hecho, en su primer período de sesiones, la Comisión declaró que el equilibrio entre las negociaciones oficiosas y las oficiales debía determinarse en función de la naturaleza del tema de que se tratase (A/7216, párr. 43). Sin embargo, como también se indica en el documento sobre el rumbo estratégico, de ese modo se corre el riesgo

de que se vea comprometida la representación universal, otro elemento de la aceptabilidad de los textos de la CNUDMI (párrs. 35 y 37 a 40).

37. La Comisión tal vez desee también estudiar maneras de simplificar la documentación, como se sugiere en el mismo documento (A/CN.9/752, párr. 36). En los párrafos 45 a 47 que figuran más abajo se examinan cuestiones relativas a la traducción de los documentos y textos de la CNUDMI.

D. Establecimiento de prioridades en el marco del programa de trabajo general de la CNUDMI

38. Mientras que en el documento sobre el rumbo estratégico se señala que la ventaja comparativa de la CNUDMI (frente a otras organizaciones que se ocupan de asuntos semejantes) reside en sus métodos de trabajo legislativo, descritos en el documento (A/CN.9/752, párrs. 35 y 37 a 40), la Comisión indicó en su 45º período de sesiones que estudiaría las sugerencias presentadas en ese documento a efectos de promover un enfoque integrado de sus diversas actividades, desde la concepción de una propuesta de proyecto legislativo hasta la prestación de asistencia técnica y el seguimiento del uso y la aprobación del texto resultante. De hecho, como se indica en el documento sobre el rumbo estratégico, las actividades de apoyo a la incorporación al derecho interno y el uso de los textos de la CNUDMI aportan significado y pertinencia a la labor legislativa de la Comisión: “Si no existen esas actividades, los textos legislativos son poco más que instrumentos de consulta” (A/CN.9/752, párr. 41).

39. Dado su nivel de recursos, actuales y previstos, así como el equilibrio entre la actividad legislativa y la correspondiente a otros aspectos del mandato, es probable que la Secretaría pueda seguir ajustando su actual nivel de actividad en pro de la aprobación y el uso de textos de la CNUDMI. No obstante, está claro que la Secretaría no puede emprender nuevas actividades, como las sugeridas como posible base para un programa de trabajo dedicado al fomento del estado de derecho a nivel nacional e internacional, que la Comisión se mostró deseosa de estudiar en el presente período de sesiones (A/67/17, párr. 230). Entre ellas cabe destacar las siguientes:

a) Apoyo a la aprobación y el uso de los textos existentes que actualmente no están respaldados por un grupo de trabajo constituido u otro tipo de labor legislativa (la lista completa de textos al 29 de mayo de 2012 puede consultarse en el anexo del documento sobre el rumbo estratégico, A/CN.9/752/Add.1);

b) Elaboración de directrices prácticas y material de formación para jueces que trabajen en ámbitos transfronterizos de la ley, además de lo que hizo el Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) respecto de la insolvencia transfronteriza;

c) Formalización de una red creando una lista de participantes (“listserve”) que permitiría a los expertos “reunirse” e intercambiar información y ayudaría a los Estados que precisaran asistencia a encontrar expertos sobre el terreno. Se citó el ejemplo de un mecanismo semejante que lanzó la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado;

d) Intensificación de la cooperación de la CNUDMI con el Banco Mundial con miras a establecer vínculos entre el desarrollo económico y el derecho mercantil

y la contribución de este último al fomento del comercio internacional y las inversiones extranjeras en los Estados que las necesiten y de un mayor grado de visibilidad e integración del derecho mercantil en el programa general de las Naciones Unidas relativo al estado de derecho, las ventajas de lo cual se describen en el documento sobre el rumbo estratégico (A/CN.9/752/Add.1, párrs. 17 a 20);

e) Seguimiento de la experiencia de aprobación y uso de textos de la CNUDMI, lo cual puede servir para determinar dónde pueden hacer falta revisiones o modernizaciones y mejorar la eficiencia de la futura labor legislativa; y

f) Determinación de los recursos y publicaciones existentes de otros órganos dedicados a la reforma y la elaboración legislativas pertinentes a los que podría recurrirse para promover la aplicación, la interpretación y la utilización de los textos de la CNUDMI y el establecimiento de mecanismos de colaboración permanente con dichos órganos.

40. La Comisión aún no se ha planteado si deben movilizarse recursos suplementarios y externos para desempeñar sus funciones, por ejemplo mediante actividades conjuntas y la cooperación con otros órganos, y, en caso afirmativo, cómo hacerlo, conforme a lo indicado en el documento sobre el rumbo estratégico (A/CN.9/752/Add.1, párr. 23). A pesar del acusado incremento de su carga de trabajo y su producción, en ese documento se señala que la Secretaría funciona hoy con aproximadamente el mismo nivel de recursos humanos y de otro tipo, en términos reales, que se le asignó poco después de su creación (A/CN.9/752, párr. 25), es decir, 14 puestos del Cuadro Orgánico y 7 de Servicios Generales, además de 1 puesto del Cuadro Orgánico y 1 de Servicios Generales para prestar apoyo al Centro Regional para Asia y el Pacífico en Incheon. De hecho, como consecuencia de los recortes presupuestarios en todas las Naciones Unidas se ha determinado la supresión de 1 puesto de Servicios Generales de la Secretaría a partir del 1 de enero de 2014, con lo cual resultará difícil garantizar que el Anuario de la CNUDMI se siga publicando. También se da por supuesto que, en el actual contexto financiero, será limitada la disponibilidad de recursos externos.

41. Además, la experiencia acumulada en los proyectos en curso de asistencia técnica y coordinación viene a indicar que el apoyo externo prestado, por ejemplo financiando los viajes de la Secretaría a actos organizados por terceros con fines de promover la aprobación y el uso de textos de la CNUDMI, puede ejercer mayor presión sobre la Secretaría a efectos de destinar recursos suficientes a la ejecución de esos proyectos.

42. En consecuencia, la Comisión tal vez desee plantearse, al evaluar la utilidad de las actividades descritas en el párrafo 39 del presente documento, si, en vista de los recursos disponibles, es óptimo el equilibrio actual entre ellas y las actividades legislativas. A ese respecto, la Comisión tal vez desee evaluar si conviene seguir prestando servicios permanentes a seis grupos de trabajo. Si se redujera a cinco el número de grupos de trabajo encargados de actividades legislativas, por ejemplo, la Secretaría podría dedicar más tiempo a estas otras actividades.

E. Cuestiones conexas

1. Apoyo de los grupos de trabajo y la Comisión a las actividades encaminadas a promover la aprobación y el uso de textos de la CNUDMI

43. En el documento sobre el rumbo estratégico se sugiere que, entre otras cosas, si se asignara tiempo en las reuniones de la CNUDMI para que los Estados compartieran información sobre las iniciativas que hubieran tomado para promover los instrumentos de la CNUDMI, los Estados que buscaran asistencia podrían tener conocimiento de iniciativas de las que podrían beneficiarse. La Comisión reservó ese tema con la idea de examinarlo posiblemente en su 46º período de sesiones (A/67/17, párr. 230).

44. Si se reserva ese tiempo al final del período de sesiones de un grupo de trabajo, antes del examen del informe de ese período de sesiones, se podría aumentar la eficiencia del período de sesiones y los Estados podrían demostrar su voluntad de fomentar la aprobación y el uso de textos de la CNUDMI. Ese tipo de examen, que no necesita de negociaciones o deliberaciones, no tendría que consignarse en el informe del período de sesiones en cuestión. Podría adoptarse un enfoque semejante, cuando proceda, en el caso de los períodos de sesiones de la Comisión.

2. Publicación de los documentos en todos los idiomas oficiales de la CNUDMI

45. La Comisión tal vez sea consciente de que cada vez resulta más difícil velar por la publicación simultánea de los documentos en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Los documentos de la CNUDMI consumen una parte importante de los recursos asignados a la traducción en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena. El aumento de las dificultades se debe, en parte, al mayor volumen de documentos de la CNUDMI, según se observa en el documento sobre el rumbo estratégico (A/CN.9/752, párr. 36), y, en parte, a otras presiones a las que están sujetas las secciones lingüísticas en cuestión. Las publicaciones de la CNUDMI se ven especialmente afectadas por el hecho de que no se preparan para una reunión en particular, por lo que no tienen que respetar un plazo en firme. En un caso reciente, es poco probable que la versión definitiva en español de un texto largo de la CNUDMI se publique hasta pasados unos dos años desde que la Comisión lo apruebe.

46. La Comisión tal vez desee también tomar conocimiento de que los recursos disponibles para traducir material para el sitio web cada vez son más limitados.

47. En consecuencia, la Comisión tal vez desee estudiar mecanismos alternativos para velar por el cumplimiento del objetivo de política por el que se trata de lograr la publicación de los documentos en todos los idiomas oficiales: la comprensión amplia de los textos de la CNUDMI. Esos mecanismos pueden consistir en recurrir a traductores externos que preparen traducciones no oficiales de textos originales o seguir con mayor frecuencia la práctica de elaborar algunos documentos únicamente en los idiomas de trabajo de las Naciones Unidas. La Comisión tal vez desee también ayudar a la Secretaría a hallar fuentes externas y, de ser necesario, apoyo financiero al respecto.

**B. Posible labor futura en la esfera de la colaboración entre
el sector público y el privado — Informe del coloquio de
la CNUDMI sobre la colaboración entre el sector público
y el privado (Viena, 2 y 3 de mayo de 2013)**

(A/CN.9/779)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-5
II. Resumen del debate del coloquio	6-71
A. Necesidad de que la CNUDMI se ocupe de la colaboración público-privada	6-35
1. Experiencia adquirida en la utilización y regulación de la colaboración público-privada desde 2003	6-18
a) Utilización de la colaboración público-privada	6-9
b) Regulación de la colaboración público-privada	10-18
2. Experiencia en la utilización de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada	19-22
3. Factores particulares que justifican que la CNUDMI se ocupe de la colaboración público-privada	23-35
B. Alcance de la posible labor de la CNUDMI sobre la colaboración público-privada	36-71
1. ¿A qué tipo de colaboración público-privada debería dirigirse la labor de la CNUDMI?	37-45
2. Criterios de regulación de la colaboración público-privada	46-55
3. ¿Qué forma o formas ha de adoptar la labor de la CNUDMI?	56-64
4. Consideraciones que han de tenerse en cuenta en la organización de la labor de la CNUDMI en la esfera de la colaboración público-privada	65-71
III. Conclusiones	72-84

I. Introducción

1. En su 45º período de sesiones, celebrado en 2012, la Comisión observó que si se seguía examinando la conveniencia y viabilidad de la futura labor en la esfera de la colaboración entre el sector público y el privado ello exigiría que la Secretaría realizase nuevas investigaciones y un estudio detallado. La Comisión convino, por tanto, en que sería útil celebrar un coloquio para determinar el alcance de la labor y los principales temas que convendría tratar. Se pidió a la Secretaría que, a modo de

preparativo para el coloquio, definiese los posibles temas de debate utilizando las disposiciones de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada¹ y sirviéndose de los recursos de otros órganos y basándose en las deliberaciones de la Comisión en su 45º período de sesiones. Se preveía que los resultados del coloquio serían presentados a la Comisión para su examen. A ese respecto, se convino también en que sería esencial definir un mandato claro relativo a toda labor futura en ese terreno².

2. Asistieron al coloquio, que se celebró en Viena los días 2 y 3 de mayo de 2013, expertos de organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales internacionales, del sector privado y de la comunidad académica. Los debates del coloquio giraron en torno a dos temas principales: a) si era necesaria la labor de la CNUDMI en la esfera de la colaboración público-privada, y b) en caso afirmativo, el alcance de dicha labor.

3. En relación con el primer tema, se examinaron los siguientes puntos: a) experiencia adquirida en la utilización y regulación de la colaboración público-privada desde 2003, último año en que la Comisión se ocupó de la esfera conexas de los proyectos de infraestructura con financiación privada; b) experiencia adquirida en la utilización de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada, y c) factores especiales que justifican la labor de la CNUDMI en la esfera de la colaboración público-privada.

4. En relación con el segundo tema se examinaron los siguientes puntos: a) qué tipos de colaboración público-privada deben examinarse en la labor de la CNUDMI; b) qué enfoques se han adoptado para regular dicha colaboración; c) qué forma o formas debe asumir la labor de la CNUDMI; y d) qué consideraciones deben tenerse en cuenta al organizar la labor de la CNUDMI en esta esfera.

5. Por la presente nota se transmiten, para su examen por la Comisión, un resumen del debate y las principales conclusiones alcanzadas en el coloquio.

II. Resumen del debate del coloquio

A. Necesidad de que la CNUDMI se ocupe de la colaboración público-privada

1. Experiencia adquirida en la utilización y regulación de la colaboración público-privada desde 2003

a) Utilización de la colaboración público-privada

6. Se observó que durante la última década, en particular desde el comienzo de la crisis financiera, había habido un creciente interés en la colaboración público-privada como medio eficiente de movilizar recursos para la prestación de

¹ La Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada (2000) y Disposiciones Legales Modelo sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada (2003); pueden consultarse en http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.

² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17)*, párr. 120.

servicios públicos. La colaboración entre los dos sectores se ha hecho popular también en el contexto de la preparación de grandes acontecimientos públicos, por ejemplo, las olimpiadas. La colaboración entre los dos sectores se ha ido utilizando cada vez más y han surgido nuevas formas de colaboración.

7. En muchos países se ha producido un cambio en cuanto a las políticas en que descansa la colaboración entre los dos sectores. En otras épocas, la falta de recursos públicos, o su insuficiencia, para financiar los servicios públicos era la principal fuerza propulsora de la utilización de la colaboración público-privada. Actualmente, se reconoce en general que la financiación por el sector privado no es el único factor que torna atractiva la colaboración entre los dos sectores; en efecto, hay otros factores, como la capacidad del sector privado de responder con soluciones innovadoras, creativas y eficientes a las necesidades públicas.

8. Si bien se consideró en otra época que el concepto de “colaboración entre el sector público y el sector privado” era una expresión normativa que se usaba solamente en los programas de desarrollo o en las proyecciones a largo plazo a nivel nacional, desde 2005 el concepto se ha definido y regulado en varios países.

9. La experiencia adquirida en la colaboración entre los dos sectores ha sido desigual: en algunos casos ha tenido gran éxito; en otros, no tanto, y los ha habido en que fracasó por completo. Las instituciones financieras internacionales y otras entidades han iniciado varios estudios para analizar las causas del fracaso de la colaboración público-privada. La conclusión parece ser que los problemas que dificultan la ejecución de la colaboración entre los dos sectores son muy específicos y dependen del contexto y la experiencia de los países en que se practica esta colaboración.

b) Regulación de la colaboración público-privada

10. En algunos países se necesitan leyes especiales que autoricen la colaboración público-privada, pero no en todos. Recientes estudios de la medida en que se regula la colaboración entre los dos sectores, como, por ejemplo, el estudio de los países en que se realizan operaciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), revelaron que existían muchas diferencias tanto en la forma de regular la colaboración como en el alcance de la legislación existente.

11. En varios países se tiende a regular por ley la colaboración público-privada, muchas veces sin el beneficio de experiencia práctica anterior alguna en su utilización. En algunos países, se ha intentado legislar la colaboración público-privada solo a nivel local o municipal, pero no a nivel nacional o federal; en otros, puede existir legislación a ambos niveles. Se consideró que solo en contados casos las iniciativas legislativas habían dado por resultado un marco legislativo coherente y amplio que, lejos de obstaculizar, facilitaba el éxito de la colaboración público-privada. La promulgación de leyes especiales sobre la colaboración público-privada en algunos países ha llevado a contradicciones en el marco legislativo. En algunos países, las leyes promulgadas sobre el tema existen solo en la letra, y no se aplican en la práctica. En otros, la promulgación de una ley sobre la colaboración público-privada ha dado lugar a la aparición de tres o más leyes que regulan las mismas cuestiones (por ejemplo, una ley sobre la contratación pública, otra ley sobre las concesiones y otra sobre la colaboración público-privada) y que pueden llegar a contradecirse mutuamente.

12. Se recordaron los textos existentes sobre la colaboración público-privada a nivel internacional y regional³. Se observó que no todos los Estados los tenían en cuenta al redactar las leyes relativas a la colaboración público-privada.

13. En algunos países, la colaboración se rige por reglamentos o guías y no por leyes. En otros, la colaboración, como tal, no está regulada en absoluto. En estos países, la colaboración puede instituirse y llevarse a cabo dentro del marco jurídico existente, es decir, utilizando una combinación de otras leyes del Estado, por ejemplo, las leyes de contratación pública o sobre concesiones. Se observó que este enfoque no siempre producía los resultados apetecidos si, por ejemplo, los estrictos requisitos de una ley de contratación pública o sobre concesiones se aplicaban a la colaboración público-privada sin las modificaciones necesarias. En particular, la insistencia en el precio como criterio de evaluación dominante, común en el régimen de contrataciones públicas, podría resultar excesiva e inapropiada en el contexto de la colaboración público-privada. Se afirmó también que las limitaciones impuestas a las negociaciones, que solían formar parte del régimen de contratación pública, tampoco dejarían suficiente margen de flexibilidad en el contexto de la colaboración público-privada.

14. En algunos países, a falta de un marco jurídico específico sobre la colaboración público-privada, se han adoptado normas para regularla sobre la base de cada proyecto en particular; en tales casos, la colaboración puede quedar sujeta a un largo y engorroso trámite de autorizaciones por los órganos legislativos o las autoridades municipales y necesitar la aprobación previa por el gobierno de los estudios de viabilidad.

15. Se citó el caso de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), donde se había emprendido una iniciativa regional para preparar una ley modelo sobre la colaboración público-privada.

16. Las leyes que regulan la colaboración varían en su alcance y grado de detalle. Algunas leyes contienen una definición de la expresión “colaboración público-privada”, en tanto que otras no la definen. Se observó la tendencia a incluir en estas leyes una amplia gama de arreglos mediante los cuales el sector privado puede participar en la prestación de servicios públicos. Algunas leyes son sumamente detalladas y regulan diversos aspectos de la colaboración (con el riesgo, según se dijo, de incurrir en una regulación excesiva), en tanto que otras son muy generales y pueden omitir la regulación de importantes cuestiones. La mayoría de las leyes regulan las relaciones contractuales emanadas de la colaboración entre los dos sectores y disponen la creación de una dependencia para la colaboración público-privada con funciones diversas. La experiencia adquirida en algunos países en la colaboración público-privada y la función desempeñada por los acreedores en el proceso han llevado a la introducción de ajustes en el marco legislativo existente con miras a dar mayor flexibilidad a las leyes y lograr que los proyectos ejecutados en virtud de esa colaboración sean “financiables”⁴. El proyecto de ley modelo que se examina actualmente en la Asamblea Interparlamentaria de la CEI abarca los acuerdos de participación en la producción y en los ingresos.

³ Véase también A/CN.9/782, sección II.B.4.

⁴ Este término se utiliza para describir los proyectos que son aceptables a los inversionistas institucionales y que, por tanto, tienden a atraer la participación de contratistas.

17. Otra tendencia que se ha observado ha sido la de incluir la colaboración público-privada entre los temas de negociación para adherirse al Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio⁵. Si la colaboración público-privada forma parte de los compromisos contraídos por un país en virtud de este Acuerdo, les serán aplicables los principios del trato nacional y la cláusula de la nación más favorecida.

18. Se examinó detenidamente la relación entre la calidad de la regulación de la colaboración público-privada y la calidad de la ejecución. Se observó que en algunos países se había llevado a cabo con éxito la colaboración sin la existencia de un marco legislativo específico. En otros países, donde la colaboración fracasó, uno de los factores contribuyentes podría haber sido la falta de un marco jurídico apropiado. Al mismo tiempo, en ciertos casos la colaboración había fracasado en países que contaban con un marco jurídico adecuado, aplicable a la cooperación público-privada. La falta de experiencia práctica en la aplicación de la colaboración público-privada podría haber sido una de las causas del fracaso en esos casos. Se reconoció que podía haber muchos factores que contribuían al éxito o el fracaso de la colaboración, incluidos la voluntad política y el interés del país huésped en un proyecto dado, y la capacidad y calidad de la aportación de todas las partes interesadas al proyecto. Si bien resultaba difícil demostrar la existencia de un vínculo causal directo entre la calidad del marco jurídico aplicable a la colaboración y su éxito o fracaso, era indiscutible que un marco jurídico inadecuado creaba barreras al establecimiento y la utilización con éxito de la colaboración público-privada.

2. Experiencia en la utilización de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada

19. Según algunos participantes, ninguno de los instrumentos jurídicos existentes a nivel nacional, regional o internacional, incluidos los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada, podía considerarse de hecho un prototipo o modelo al que pudieran recurrir los Estados para basar su reforma legal de la colaboración público-privada. Otros participantes consideraron que los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada podían tomarse como modelo, y proporcionaron ejemplos de leyes sobre la colaboración público-privada en los países de la CEI, Europa oriental, África septentrional, China y Mongolia, que se habían inspirado en esos instrumentos. El BERD informó que los había utilizado para evaluar la legislación relativa a la colaboración público-privada en 34 países en que tenía operaciones, y los consideró una útil herramienta de referencia. Se destacó, en particular, la utilidad de esos instrumentos porque se ocupaban de temas que trascendían la mera selección del operador de un proyecto, etapa relativamente simple en que se aplicaban los principales principios de una política de contratación pública racional. Se subrayó

⁵ El Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, negociado paralelamente a la Ronda Uruguay de 1994, entró en vigor el 1 de enero de 1996. El 15 de diciembre de 2011, los negociadores llegaron a un acuerdo sobre los resultados de la nueva negociación del Acuerdo sobre Contratación Pública. Esta decisión política fue confirmada, el 30 de marzo de 2012, mediante la aprobación oficial de la Decisión sobre los resultados de las negociaciones celebradas de conformidad con el artículo XXIV:7 del Acuerdo sobre Contratación Pública (GPA/113). Pueden consultarse ambos textos en http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/gp_gpa_s.htm.

que no todos los Estados ni todas las instituciones o particulares que utilizaban los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada reconocían este hecho.

20. Algunos oradores señalaron que, pese a que algunos Estados y organizaciones los habían usado como punto de referencia para las reformas legislativas, los instrumentos de la CNUDMI no eran muy conocidos. Habían demostrado ser, sí, una fuente útil de información, pero principalmente para expertos y miembros de la comunidad académica de países e instituciones que tenían amplia experiencia en la colaboración público-privada. En otros casos, especialmente en el de países con poca o ninguna experiencia en ese campo, resultaban excesivamente complejos y no reflejaban las necesidades y realidades inmediatas sobre el terreno, de modo que habían resultado de utilidad limitada para legisladores y reguladores. Los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada no reflejaban las características regionales, las características peculiares de la colaboración público-privada en diversas esferas (agua, salud, red vial, etc.) ni permitían a los países hacer una transición gradual de formas simples de colaboración a otras más complejas. Más bien tendían a apabullar al lector con conceptos complejos, sin tener en cuenta que este podía no comprender todavía incluso conceptos simples en el contexto de la colaboración público-privada como, por ejemplo, qué es lo que constituyen medidas de respaldo público y qué cabe considerar riesgos que corren las partes en contraposición a responsabilidades u obligaciones.

21. Algunos oradores expresaron su preocupación por el hecho de que, si bien los instrumentos de la CNUDMI abordaban la mayoría de los tipos de colaboración público-privada y de proyectos de infraestructura con financiación privada, no trataban de otras formas de colaboración que se habían generalizado después de 2003 (por ejemplo, la formación de asociaciones y alianzas). Otros consideraron, en cambio, que los instrumentos de la CNUDMI podían solo parecer no estar al día a ese respecto pero habían sido preparados deliberadamente con un alcance limitado y con la atención centrada principalmente en el desarrollo de la infraestructura. Algunos proyectos habían sido excluidos del estudio deliberadamente (como las concesiones para la explotación de petróleo y gas y los proyectos de colaboración institucional entre el sector público y el privado). También había sido una decisión fundamentada la de abordar en los instrumentos solo los problemas básicos de los proyectos de infraestructura con financiación privada y orientar a los Estados promulgantes en cuanto a las demás esferas del derecho en que sería necesario introducir reformas para que el marco jurídico resultara aplicable a esos proyectos de manera consecuente y completa.

22. En respuesta a las inquietudes suscitadas por la complejidad de los instrumentos de la CNUDMI, se explicó que era la complejidad de los proyectos lo que obligaba a ocuparse de cuestiones complejas. La falta de capacidad en algunos países para emprender la colaboración público-privada no debería significar que la calidad de los textos de la CNUDMI se vea comprometida al adoptar un enfoque excesivamente simplista en el tratamiento de cuestiones que no son simples; y tampoco debería rebajarse el carácter de dichos instrumentos al de documentos simplemente educativos. Los instrumentos de la CNUDMI deben reflejar las mejores prácticas en la regulación de la colaboración público-privada. También se señaló que las quejas relativas a la complejidad podían ser válidas en cuanto a la

Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada pero no en cuanto a las Disposiciones Legales Modelo sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada. La primera es, por cierto, larga y compleja, pero ello se justifica porque la Guía es un instrumento analítico que explica diversas opciones y las consecuencias de cada una. Las Disposiciones Legales Modelo, en cambio, son un texto corto y simple, que proporciona orientación a los Estados en cuanto a las disposiciones básicas que deben incluirse en la legislación sobre los proyectos de infraestructura con financiación privada.

3. Factores particulares que justifican que la CNUDMI se ocupe de la colaboración público-privada

23. Como se desprende del debate resumido en la sección 1, son cada vez más los Estados que han empezado a regular la colaboración público-privada y están apareciendo más definiciones de este concepto. Actualmente existe una considerable confusión en cuanto a la terminología, el ámbito de aplicación apropiado de un régimen de colaboración público-privada, su contenido y la interacción con otras esferas jurídicas, los aspectos políticos y las consideraciones normativas (comercio, gobernanza y empleo). Las leyes deficientes dan por resultado proyectos deficientes, sobre todo porque llevan a costos excesivos de las operaciones debido a la necesidad de preparar y negociar complejos contratos que deben colmar las lagunas y salvar las contradicciones del marco jurídico existente. Esto no favorece la utilización eficiente de los recursos públicos, privados o de la asistencia al desarrollo. Las reformas institucionales que han acompañado a las iniciativas legislativas han vuelto el problema aún más complejo pues han llevado a la proliferación de las instituciones estatales que se ocupan de cuestiones relacionadas con la colaboración público-privada. Se observó que este problema no existía antes de 2003, cuando solo había unas pocas instituciones nacionales encargadas de los problemas de la colaboración público-privada, tales como las dependencias de colaboración público-privada (designación común de las entidades encargadas de las cuestiones normativas y prácticas de esa colaboración).

24. Se opinó que la comunidad internacional, es decir, las instituciones internacionales, regionales y subregionales, no había logrado orientar a los Estados en cuanto a las reformas legislativas o institucionales necesarias en esta esfera. La situación se caracterizaba por la falta de coordinación entre las actividades de establecimiento de normas, prestación de asistencia técnica y creación de capacidad, con resultados contradictorios y la confusión consiguiente. Era urgente, por tanto, según los participantes que habían planteado la cuestión, que todas las organizaciones que elaboraban leyes modelo sobre la colaboración público-privada o directrices sobre la forma de preparar y aplicar un régimen nacional de colaboración público-privada adoptaran un enfoque integrado.

25. Por consiguiente, se instó a la CNUDMI a que abordara todas esas dificultades que enfrentaban los Estados cuando preparase una ley coherente sobre la cooperación público-privada. En vista de su mandato de coordinar las actividades de diversas organizaciones de preparación de textos jurídicos en la esfera del derecho mercantil internacional, la CNUDMI podía garantizar que la comunidad internacional, inspirada en un modelo de la CNUDMI, empezara a hablar con una sola voz. La situación actual era la contraria y los instrumentos de la CNUDMI sobre los proyectos de infraestructura con financiación privada no bastaban para remediarla. Los oradores

consideraron que ese era el momento oportuno para analizar cuáles eran las causas de la situación y cómo remediarla.

26. Con el tiempo, se ha ido recurriendo cada vez más a la colaboración público-privada, en las formas y los contextos más diversos, y lo más probable es que se siga utilizando en un ámbito de contextos y formas cada vez más amplio. Un estudio de la legislación relativa a los proyectos de infraestructura con financiación privada y a la colaboración público-privada en todo el mundo reveló que las leyes sobre la colaboración contenían algunos elementos ausentes en las leyes sobre los proyectos de infraestructura con financiación privada, incluidos los instrumentos de la CNUDMI, debido a las características distintivas de los proyectos de colaboración público-privada que no estaban relacionados con la infraestructura. Se sostuvo, por consiguiente, que el alcance de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada debía ampliarse regulando algunos o todos los tipos de colaboración público-privada que por el momento habían quedado a un lado.

27. Dado que la colaboración público-privada ha demostrado ser de suma eficacia en ciertas circunstancias pero contraproducente en otras, se consideró que un análisis de la experiencia adquirida en su aplicación contribuiría a determinar qué factores habían contribuido al éxito y cuáles al fracaso. Por consiguiente, habría que prever garantías contra los abusos y los errores más comunes. Habría que agregar algunas garantías omitidas en los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada y otras que sí existían en dichos instrumentos habría que reformularlas o revisarlas a fin de reflejar la realidad.

28. Se señaló, a este respecto, que los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada carecían actualmente de algunas importantes garantías y disposiciones, por ejemplo, disposiciones sociales y otras medidas para promover la responsabilidad social y los proyectos en favor de los pobres. Como se sugirió en el Congreso de la CNUDMI titulado “Derecho moderno para un comercio globalizado” (Viena, 9 a 12 de julio de 2007)⁶, las disposiciones encaminadas a anticipar y minimizar las controversias entre la autoridad contratante y el operador de un proyecto debían formularse de manera que se mantuviesen relaciones satisfactorias entre las partes contratantes básicas en la colaboración público-privada. Estos mecanismos preventivos pueden incluir la celebración de reuniones periódicas, avisos de alerta sobre posibles cambios en la legislación y reglamentos y el establecimiento de comisiones permanentes en distintos sectores, listas para intervenir en caso de litigio.

29. Algunas garantías incluidas en los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada no se han utilizado en medida suficiente. Por ejemplo, las destinadas a asegurar la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser aplicables no solo en la etapa de la selección del operador del proyecto sino en todo el proyecto. Se destacó, en particular, la necesidad de hacer pública la información acerca del movimiento de recursos del Estado al operador del proyecto y viceversa. Deberían robustecerse las medidas contra la corrupción desalentando, por ejemplo, las reuniones individuales privadas y fomentando en

⁶ Véase *Proceedings of the Congress*, capítulo V; puede consultarse en www.uncitral.org/pdf/english/congress/09-83930_Ebook.pdf.

cambio el uso de los medios públicos y las formas modernas de comunicación para dejar una constancia más transparente de las operaciones.

30. Se agregó que otra esfera que debía desarrollarse en los instrumentos de la CNUDMI sobre los proyectos de infraestructura con financiación privada era el de la solución eficaz de las controversias. Los instrumentos de la CNUDMI no abordan de manera detallada la complejidad de los mecanismos de solución de controversias que suelen intervenir en los proyectos de colaboración público-privada ni el papel de importancia crítica que desempeña la elección de la ley aplicable y del foro para la solución eficaz de las controversias. Hay distintos conjuntos de acuerdos que pueden referirse a diversas normas de arbitraje y leyes aplicables, así como los foros donde han de resolverse las controversias. Debería explicarse la interacción entre estos distintos elementos.

31. También se expresó la opinión de que las Disposiciones Legales Modelo de la CNUDMI y las disposiciones pertinentes de la Guía sobre la solución de controversias podrían tratar de encontrar un equilibrio más justo entre los diversos foros para la solución de controversias, por ejemplo, el arbitraje internacional en contraposición a los mecanismos nacionales de solución de controversias. La solución de controversias mediante el arbitraje internacional no ha dado buenos resultados en muchos casos, sobre todo en lo relativo a la ejecución de sentencias arbitrales internacionales. Y ello, a pesar de las disposiciones de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958 (la Convención de Nueva York)⁷, que son vinculantes para la gran mayoría de los Estados. La proliferación de los foros, los casos y las sentencias de arbitraje internacional, junto con la proliferación de los tratados de inversión, han complicado la solución de controversias mediante el arbitraje internacional. Es posible que en los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada haga falta hacer mayor hincapié en la importancia de disponer de mecanismos nacionales eficaces de solución de controversias, así como en la necesidad de crear capacidad local para tal fin.

32. Se recomendó que, de efectuarse este cambio de orientación, se hiciera sin comprometer el entorno propicio para el arbitraje internacional. En particular, debería permitirse por ley a la autoridad contratante convenir en el arbitraje internacional en virtud de un contrato de colaboración público-privada; en muchos ordenamientos jurídicos, este enfoque actualmente no es posible aunque el marco jurídico pueda permitir, en general, el arbitraje internacional. Se instó a la CNUDMI a que, en toda labor futura sobre la colaboración público-privada, se ocupara también de otros obstáculos que se oponen a la solución eficaz de las controversias planteadas en la colaboración público-privada: a) la experiencia, las técnicas y los conocimientos necesarios del poder judicial para conocer de cuestiones complejas de colaboración público-privada; b) deficiencias de los sistemas judiciales; c) falta de independencia; d) accesibilidad (los procedimientos pueden discriminar contra los inversionistas extranjeros en contraposición a las entidades nacionales); y e) renuencia a nivel nacional (por toda una serie de razones) a ejecutar las

⁷ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 330, núm. 4739. También puede consultarse en http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html (visitado en mayo de 2013).

sentencias arbitrales internacionales pese a las obligaciones internacionales contraídas por los Estados en virtud de la Convención de Nueva York y otros tratados multilaterales y bilaterales. Se señaló que también debían tratarse con mayor detalle las cuestiones relacionadas con los actos soberanos y las inmunidades soberanas, pues había habido casos de abuso, en que se habían hecho objeciones y excepciones invocando la inmunidad soberana.

33. Se afirmó que las propuestas no solicitadas representaban otra esfera en que hacía falta una orientación más concreta de la CNUDMI. Los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada permitían la consideración de propuestas no solicitadas con prudencia y a reserva de ciertas garantías de transparencia, pero se consideró que en la práctica esta esfera adolecía de deficiencias y se prestaba al abuso, especialmente en los países sin garantías institucionales y de transparencia. Se propuso que se fortalecieran considerablemente las disposiciones en la materia recurriendo a la experiencia positiva adquirida desde 2003 en la regulación de las propuestas no solicitadas en todo el mundo. El criterio principal consistía en mantener la competencia, pero protegiendo al mismo tiempo los derechos de propiedad intelectual y fomentando la creatividad y la innovación. Sin embargo, se advirtió contra la regulación detallada de este tema controvertido. Todo texto reglamentario sobre el tema debería ir acompañado, inevitablemente, de extensas notas explicativas. Se observó también que el concepto mismo de propuesta no solicitada dependía de la definición de la colaboración público-privada: en efecto, cuando el centro de atención en esta definición se orienta hacia la prestación de servicios públicos, la probabilidad y justificación para aceptar propuestas no solicitadas es mínima puesto que el sector privado no puede definir mejor que el sector público lo que el público necesita. Se agregó que el concepto de propuestas no solicitadas no debía confundirse, empero, con otros conceptos afines, como el de las propuestas del sector privado.

34. Algunos participantes consideraron que otras disposiciones de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada, en particular la distribución de los riesgos, las garantías públicas y las medidas de respaldo público debían refinarse un poco más pues en la práctica existía considerable confusión respecto de esas cuestiones. Se consideró que algunas otras disposiciones de los instrumentos de la CNUDMI transmitían mensajes incorrectos o creaban una impresión falsa, por lo cual sería necesario volver a formularlas.

35. Otros factores que, según algunos participantes, podían afectar toda decisión de la CNUDMI de emprender actividades en esta esfera, incluían los acontecimientos en la escena internacional, como, por ejemplo, la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Nueva York, 31 de octubre de 2003)⁸. Este instrumento contiene disposiciones pertinentes para la colaboración público-privada. La evolución de la propia CNUDMI, en particular las nuevas normas legislativas en las esferas de la contratación pública, el régimen de la insolvencia y las garantías reales, puede exigir la revisión de algunas disposiciones de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada.

⁸ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 2349. También se puede consultar en www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf.

B. Alcance de la posible labor de la CNUDMI sobre la colaboración público-privada

36. Como se explica con mayor detalle en las secciones que siguen, no hubo desacuerdo entre los oradores en cuanto a que, en vista de los hechos mencionados, la CNUDMI debía proporcionar orientación en materia de colaboración público-privada, que se necesitaba urgentemente. Las opiniones variaban en cuanto a la forma que debía asumir dicha orientación; por ejemplo, una ley modelo o una guía legislativa ampliada y revisada, recomendaciones legislativas y disposiciones modelo. Si bien la idea de una ley modelo tuvo fuerte apoyo, algunos oradores no estaban convencidos de que la formulación de una ley modelo fuera conveniente o viable. Distintas consideraciones, incluido el tiempo que la CNUDMI dedicaría a su labor en materia de colaboración público-privada, de emprenderla, influiría en la decisión definitiva de la Comisión sobre la medida y forma de cualquier labor prevista en esta esfera.

1. ¿A qué tipo de colaboración público-privada debería dirigirse la labor de la CNUDMI?

37. Hubo consenso en que sería esencial llegar a una noción común de la colaboración público-privada para definir con exactitud el alcance de la labor. No hubo desacuerdo en cuanto a la idea de que dicha colaboración debía mantenerse flexible a fin de abarcar todas las formas posibles de participación del sector privado en la prestación de servicios públicos. Este enfoque llevaría a un concepto genérico, que, a su vez, podría dividirse en subcategorías, más que a una definición estricta de la colaboración público-privada.

38. Para tal fin, la CNUDMI tendría que determinar qué características tenían en común los tipos de colaboración público-privada que la Comisión habría de regular, y qué los diferenciaba de formas afines de actividades público-privadas que no quedarían comprendidas dentro de los límites de la labor emprendida. Se afirmó que la presencia de infraestructura física no debía considerarse un componente indispensable de los tipos de colaboración público-privada que habría de regular la CNUDMI. Se expresaron diversas opiniones en cuanto a si la futura labor de la CNUDMI en esta esfera debía abarcar la formación de asociaciones y alianzas, las formas institucionales de colaboración público-privada y los contratos de arrendamiento a largo plazo, los contratos de arrendamiento y de gestión, así como las concesiones para la explotación de recursos naturales.

39. El coloquio examinó de manera preliminar las características más distintivas de la colaboración público-privada que debía regular la CNUDMI, comparándolas, en particular, con el régimen de contratación pública y las concesiones para la explotación de recursos naturales.

40. En un proyecto de contratación pública -se observó- se presume que el gobierno financiará el proyecto desde el principio. Independientemente de que el pago al proveedor o contratista se haga al principio o al final del proyecto o en cuotas, la operación tiene consecuencias inmediatas para el presupuesto público; el aumento de la deuda pública resulta claramente visible. En el contexto de la colaboración público-privada, generalmente se supone que ha de ser el sector privado, no el público, el encargado de financiar el proyecto desde un comienzo, si

bien las fuentes de financiación del proyecto en etapas posteriores de su ejecución pueden variar. Se señaló que los efectos de la colaboración público-privada en los procesos de preparación del presupuesto público eran menos claros; esta era una de las esferas, precisamente, en que, según los expertos, la CNUDMI debía proporcionar orientación, teniendo en cuenta los ciclos presupuestarios a corto plazo de muchos países, que no se prestan para el carácter a largo plazo de la colaboración público-privada. Se consideró que la distribución de los riesgos era otra característica que diferenciaba la colaboración público-privada de la contratación pública: los riesgos de ejecución en la contratación pública recaen principalmente en el sector público, a diferencia de la colaboración público-privada, en que los riesgos de los proyectos se distribuyen entre el sector privado y el público. Se expresaron dudas, empero, de que dicho sistema de distribución estricta de los riesgos fuera válido para todos los casos de contratación pública y de colaboración público-privada.

41. La mayoría de las concesiones para la explotación de recursos naturales, se explicó, supone el aprovechamiento del patrimonio público o de bienes públicos, más que la prestación de servicios públicos, con el resultado de que las concesiones ejercen una influencia menos directa en el público que la colaboración público-privada. Se sostuvo que esta característica de las concesiones no debía justificar que se las eximiese de los principios rectores de la contratación: competencia, transparencia y responsabilidad, especialmente porque el patrimonio público debía explotarse en beneficio de todos y existían ejemplos de concesiones (por ejemplo, la explotación de recursos hídricos) que entrañaban o afectaban a la prestación de servicios públicos. Otra característica distintiva de dichas concesiones, por lo menos en el sector de la minería, se afirmó, es que no presuponen la intervención permanente de las autoridades públicas en la ejecución del proyecto; estas participan generalmente en la distribución de las utilidades y otros tipos de arreglos auxiliares.

42. Algunos participantes señalaron las siguientes características distintivas de la colaboración público-privada: a) la participación a largo plazo del sector privado en la prestación de servicios públicos; b) el carácter de la colaboración público-privada puede estar sujeto a modificaciones y ajustes con el paso del tiempo; c) las consideraciones del ciclo vital del proyecto, que debe funcionar de manera sostenible y sostenida, son las de mayor importancia (en particular por la necesidad de proporcionar servicios al público sin interrupción); d) la primacía de la autoridad pública, que sigue siendo responsable de la prestación de los servicios públicos durante toda la ejecución del proyecto y posteriormente; e) la oportunidad de que el sector privado introduzca innovaciones y aporte ideas originales; y f) distintos sistemas de pago de financiación del proyecto al sector privado por los servicios prestados.

43. Algunos oradores dijeron que las características más distintivas de la colaboración público-privada eran la participación a largo plazo del sector privado en la prestación de servicios públicos y el hecho de que el gobierno se mantuviera responsable ante el público de la prestación de servicios públicos. Se afirmó que esas características tenían consecuencias a corto y a largo plazo en la estructura, la formación y las cláusulas del contrato y la ejecución del proyecto. Puesto que, en última instancia, los beneficiarios de la colaboración público-privada son las personas, y puesto que el interés público es más importante en este tipo de colaboración público-privada que en otros tipos, el régimen de regulación de la

colaboración público-privada debería limitar la libertad de las partes en cuanto a las condiciones estipuladas. Así, por ejemplo, todo contrato debe ofrecer las garantías necesarias en caso de rescisión, a fin de asegurar la continuidad de los servicios públicos. El régimen también debería tener en cuenta cuestiones delicadas como la no discriminación en la prestación de los servicios públicos y una participación equitativa en las utilidades. Otros participantes señalaron que algunos tipos de contratación pública también suponían la prestación a largo plazo de servicios públicos por el sector privado; la contratación pública no debía reducirse simplemente a las adquisiciones hechas al proveedor como resultado de la introducción de la colaboración público-privada.

44. Por lo que se refiere a las concesiones de explotación minera en particular, se expresó la firme opinión de que la CNUDMI no debía prever la regulación de un sector tan decididamente político e internacionalmente delicado, que, en gran medida, se regula solo (la actividad minera está regulada por los códigos de minería y en algunos países estas actividades pueden estar sujetas a regímenes especiales aprobados por el órgano legislativo). También se señaló que, a diferencia de la colaboración público-privada que debería regular la CNUDMI, estas concesiones para la explotación de recursos naturales no tenían una influencia directa en las necesidades inmediatas del público.

45. Se invitó a la CNUDMI a que examinara la colaboración público-privada con la participación de empresas de propiedad estatal y junto con nuevas formas de colaboración público-privada vinculadas a los pagos por disponibilidad o los proyectos de infraestructura financiados con capital privado. Se señaló asimismo que la CNUDMI tendría que prestar mayor atención a la colaboración público-privada transfronteriza en vista de su aparición en algunas subregiones y la probabilidad de que se hiciera más común, en particular en el contexto de la integración económica subregional y regional. Pueden presentarse problemas privativos de este tipo de colaboración: ley aplicable, conflictos de leyes, institución supranacional, aplicación extraterritorial de las normas, etc.

2. Criterios de regulación de la colaboración público-privada

46. Se propuso que la CNUDMI apuntara a formular principios generales de regulación de los elementos comunes de la colaboración público-privada. No debía escogerse un modelo único de colaboración para la regulación sino que debía abordarse una amplia gama de actividades de colaboración público-privada. Se afirmó que era esencial limitar de este modo un texto de la CNUDMI a un alto nivel de marco genérico, adaptable a las circunstancias locales, si se quería que la labor de la CNUDMI en la materia resultara viable y útil; en caso contrario, el proyecto resultaría demasiado prolongado y complejo para satisfacer la urgente necesidad de una norma más general de la CNUDMI sobre la colaboración público-privada. Se dijo, además, que la regulación de elementos concretos de todos los tipos de esta colaboración sería inútil puesto que, en última instancia, serían definidos por la cultura local y las necesidades de cada proyecto.

47. Se afirmó que el objetivo de toda regulación sería permitir y facilitar distintas formas de colaboración público-privada para la prestación de mejores servicios públicos y el desarrollo sostenible.

48. Los participantes estuvieron de acuerdo en que la labor debía definir sus propios límites, observando que no todos los problemas son susceptibles de solución jurídica. Por ejemplo, la CNUDMI no debía tratar de regular las cuestiones de política en que descansa la utilización de la colaboración público-privada o cuestiones inseparables del derecho constitucional (por ejemplo, la primacía de la propiedad colectiva sobre la propiedad privada). La CNUDMI debería centrar la atención en categorías de cuestiones que exigen una solución legislativa, por ejemplo, la distribución de facultades y riesgos, y los obstáculos jurídicos, es decir, la autoridad y facultad para participar en la colaboración público-privada, y las contradicciones de las políticas y leyes sobre la colaboración público-privada con otras ramas afines del derecho (insolvencia, tributación), así como en las normas y garantías básicas que examinarán los inversionistas para asegurarse de que el proyecto sea financiable (es decir, derechos de intervención, transparencia y otros sólidos principios de la contratación, garantías contra la expropiación).

49. Al regular la colaboración público-privada debería centrarse la atención en la necesidad de dar viabilidad a los proyectos apropiados y de reducir el costo de las operaciones, que en algunos casos puede minimizarse o evitarse gracias a un marco jurídico adecuado. Por ejemplo, la inclusión en las leyes o los reglamentos de los principios básicos relativos a las tarifas podría obviar la necesidad de realizar prolongadas negociaciones con las autoridades locales.

50. Se instó a que se tratara de encontrar el equilibrio justo entre el rigor académico y las soluciones pragmáticas. Debían encararse los aspectos prácticos de, por ejemplo, cómo ha de mantenerse responsable el sector público ante la población y comprometido durante toda la ejecución del proyecto, al igual que las tendencias tales como las nuevas formas de urbanización, la lucha contra el fraude y la gestión de los identificadores. Con respecto a esta última cuestión, se sugirió que la CNUDMI considerase la posibilidad de establecer un registro mundial de transparencia, que permitiría examinar el historial de cada empresa en la ejecución de actividades de colaboración público-privada en todo el mundo, para beneficio de los gobiernos, que podrían consultar el registro. Se expresó inquietud por el hecho de que el riesgo de fraude comercial en los países en desarrollo fuera muy real, por lo cual se hacía necesario proporcionar instrumentos para que la comunidad internacional combatiera la delincuencia económica de este tipo a nivel internacional.

51. También se alentó a la CNUDMI a que indicase con claridad qué aspectos deberían tratarse en la legislación primaria y cuáles en los reglamentos y directrices, a fin de garantizar un nivel adecuado de previsibilidad y seguridad del marco jurídico aplicable a la colaboración público-privada. Este enfoque garantizaría también que el marco jurídico básico relativo a la colaboración público-privada no dependiera de un gobierno o de un ministro, y, por consiguiente, ningún cambio de gobierno tendría un efecto directo en la formación y ejecución de la colaboración público-privada. Actualmente, existen estos riesgos en algunos países debido a que en ellos cuestiones fundamentales que afectan a la colaboración público-privada se relegan a reglamentos o directrices. Sin embargo, esto no significa que todos los problemas fundamentales deban tratarse en una sola ley; en efecto, se observó que las leyes relativas a las aduanas, la tributación, la protección de las inversiones, los derechos sobre las tierras, el régimen de la insolvencia, los intereses de la seguridad y demás también eran pertinentes.

52. Por consiguiente, el marco jurídico de la colaboración público-privada debía estar en condiciones de interactuar con otras leyes aplicables al proyecto. En particular, se observó que habría que tratar de lograr cierto grado de armonización entre las leyes de contratación pública y las de colaboración público-privada, haciendo las remisiones necesarias, puesto que ciertas disposiciones podrían resultar igualmente aplicables en los marcos de la contratación pública y la colaboración público-privada. Entre los ejemplos mencionados figuraban los problemas con que tropieza un órgano independiente y los recursos disponibles para los inversionistas damnificados. Un texto de la CNUDMI sobre la colaboración público-privada tendría valor añadido en la medida en que regulase características específicas de la colaboración público-privada que exigen un mayor margen de flexibilidad que la permitida normalmente en la legislación relativa a la contratación pública, con lo cual se evitaría crear desincentivos y obstáculos a la colaboración público-privada.

53. Se insistió en que la CNUDMI no podría evitar ocuparse de la cuestión de las reformas institucionales a fin de encarar la realidad: las instituciones que tienen por fin prestar apoyo a la colaboración público-privada deberían ser compatibles y coherentes; debería evitarse la tendencia a crear nuevas entidades burocráticas, pues ello agregaría un nivel innecesario de complejidad. A este respecto, se observó que sería conveniente el establecimiento de estructuras más flexibles (por ejemplo, una junta consultiva sobre cuestiones normativas con una composición precisa, concebida para reflejar el sector en que se emprende la colaboración público-privada).

54. Se agregó que la CNUDMI debería promover un enfoque gradual de introducción de la colaboración público-privada en los países carentes de experiencia en la materia (de tipos simples de colaboración a otros más complejos), y debería ofrecer opciones a Estados con distintos niveles de capacidad. Se observó que aun en casos en que se cuenta con un sólido marco jurídico, no se recurre a la colaboración público-privada si la sociedad y las autoridades públicas no están listas para hacerlo.

55. Se agregó que debían abordarse los problemas de terminología y que cualquier texto futuro debería redactarse en términos simples para asistir al lector.

3. ¿Qué forma o formas ha de adoptar la labor de la CNUDMI?

56. Muchos oradores expresaron su preferencia por una ley modelo en la forma de un texto de la CNUDMI sobre la colaboración público-privada, especialmente teniendo en cuenta todos los hechos mencionados. Sin embargo, se reconoció que el carácter del contrato social en los Estados era muy diferente y, por consiguiente, también lo eran las necesidades en cuanto a la regulación de la colaboración público-privada. En consecuencia, no todos los países necesitarían o desearían promulgar una ley sobre la colaboración público-privada. En los casos en que exista la necesidad y la voluntad de hacerlo, una ley modelo de la CNUDMI proporcionaría a los Estados un prototipo aceptado internacionalmente, de fácil uso y acceso, para la promulgación de una ley nacional sobre la colaboración público-privada. Se afirmó que, sin ese modelo, se corría un grave riesgo de que los Estados adoptasen leyes mal concebidas. Disponiendo en cambio de un modelo, los Estados estarían en condiciones de prestar atención a las particularidades locales y efectuar en el modelo los ajustes necesarios. De este modo, una ley modelo de la CNUDMI proporcionaría el grado necesario de confianza a los encargados de formular políticas y los legisladores de que toda ley formulada sobre la base del

modelo de la CNUDMI reflejaría las mejores prácticas internacionales. Esto, a su vez, enviaría una señal positiva al sector privado en cuanto a la solidez y estabilidad del marco jurídico local aplicable a la colaboración público-privada.

57. Se sugirió que una ley modelo debería tener las siguientes características: no debería ser demasiado complicada; debería ser flexible; debería incluir las mejores prácticas respecto de las cuales existiese consenso internacional, pero las cuestiones controvertidas o discutidas no deberían incluirse, en cambio, en sus disposiciones; debería abarcar todas las disposiciones básicas aplicables a todos los tipos de colaboración público-privada regulados por la ley modelo y debería contener remisiones a otras ramas del derecho en caso necesario; la ley debería definir las principales expresiones relacionadas con la colaboración público-privada utilizadas en la ley; la ley debería tratar de las obligaciones de las partes en la colaboración público-privada, las obligaciones y medidas de respaldo público, los mecanismos de supervisión, incluida la participación de la sociedad civil, la indemnización en caso de rescisión, el arbitraje internacional y los derechos de intervención. También debería exigir que el contrato de colaboración público-privada previese estas cuestiones si la propia ley no prescribía una solución concreta al respecto. La ley debería indicar claramente qué disposiciones de cumplimiento obligatorio han de redactarse individualmente para cada proyecto, determinando cuáles son los requisitos mínimos aplicables a cada una. Las Disposiciones Legales Modelo de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada, que tratan de muchos de los puntos mencionados, deberían servir de base a dicha ley modelo.

58. Otras opciones que se consideraron para una posible labor de la CNUDMI en esta esfera fueron las de actualizar, revisar y ampliar el alcance de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada. Se recordó que cuando se prepararon esos instrumentos, los gobiernos expresaron cierta reserva en cuanto a la labor en esferas que no eran de competencia básica de la CNUDMI (problemas de relaciones bilaterales, cuestiones políticamente delicadas, instituciones nacionales). Se planteó la cuestión de si los gobiernos se mostrarían menos renuentes a hacerlo en la actualidad. Por esta razón, una ley modelo que exigiese un alto grado de especificidad, amplitud y armonización en estas esferas no era una opción que pudiera contemplarse.

59. Se sugirió, además, que la complejidad del tema y la necesidad de retener la mayor flexibilidad posible a fin de no desalentar las innovaciones en la colaboración público-privada, aconsejaban proporcionar una orientación analítica más general, como la contenida en la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada. Según se observó, en ella se indican los obstáculos jurídicos a este tipo de proyecto, se explican las consecuencias de tales obstáculos si los Estados no los encaran y se señalan otros obstáculos, fuera de los jurídicos, que también han de superarse. Con esta información analítica, la Guía ofrece a los encargados de formular políticas y a los legisladores distintas opciones frente a la reforma legislativa e institucional.

60. En respuesta, los partidarios de la preparación de una ley modelo consideraron que la actualización, revisión y ampliación del alcance de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada no producirían los resultados apetecidos, es decir, la preparación de un modelo de fácil uso para los legisladores. Se consideró esencial que la CNUDMI preparase un modelo internacional de ese tipo que, a su vez, debería ir acompañado de materiales

complementarios, como observaciones sobre las disposiciones de la ley modelo, orientación sobre cuestiones concretas que generan la mayoría de las dificultades en la ejecución práctica de la colaboración público-privada y documentos normativos.

61. Algunos participantes expresaron la convicción de que la ley modelo no podría proporcionar una solución única a todos los problemas de la colaboración público-privada que debería abarcar una ley modelo. Por consiguiente, se subrayó que, si bien el texto de la ley podría ser útil, sería absolutamente necesario acompañarlo de una guía (como la proporcionada, por ejemplo, en la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública⁹), a fin no solo de dotar a los encargados de aplicar la ley de los medios necesarios para hacerlo sino también para explicarles las posibles desviaciones del modelo o las distintas opciones contenidas en este. Una orientación explicativa de ese tipo comprendería también el examen de cualquier cuestión controvertida respecto de la cual no se hubiera llegado a un consenso.

62. Se sugirió la posibilidad de actualizar la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada al mismo tiempo que se preparaba un ley modelo, de modo que el texto actualizado resultante pudiera constituir la base para la redacción de una guía para su incorporación en el derecho interno que explicaría las disposiciones de la ley modelo y proporcionaría una orientación técnica más detallada a los ministerios y otros departamentos de gobierno que recurran a la colaboración público-privada. El criterio con que se redactaría una guía de este tipo, se insistió, debería considerarse cuidadosamente desde el punto de vista de los usuarios finales a quienes estaba dirigido el texto, a fin de evitar ciertos errores que contenía la Guía actual. Si bien la guía tendría que ser específica y detallada, debería estar redactada en términos simples y fáciles de comprender por sus destinatarios. Habría que evitar los términos complejos e incluir ejemplos y explicaciones ilustrativas, así como diversas formas de presentar, de manera accesible, lo que, cabía prever, sería un material voluminoso (es decir, que la guía podría dividirse en secciones e ir acompañada de anexos que describieran, por ejemplo, características específicas de la colaboración público-privada en cada sector). También se sugirió la posibilidad de preparar un glosario de términos relacionados con la colaboración público-privada. Podría incluirse en la guía, asimismo, un conjunto de cláusulas contractuales esenciales, similares a las normas y los procedimientos de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), en un anexo o de otro modo, que podrían resultar de utilidad para las partes contratantes, pues podrían incorporarlas por remisión en su contrato de colaboración público-privada, ahorrándose la necesidad de negociarlas. Este conjunto de cláusulas podría utilizarse también como lista de verificación de las disposiciones básicas que deberían incluirse en el contrato.

63. Se sostuvo, en apoyo de la labor sobre una ley modelo y su guía para la incorporación en el derecho interno y otros materiales complementarios, que el paso de las disposiciones legales modelo y la guía legislativa existentes a una ley modelo con la guía para su incorporación al derecho interno representaría una enorme ayuda

⁹ Aprobada por la Comisión en su 45º período de sesiones, celebrado en 2012. *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17)*, párr. 46. Puede consultarse en http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2012Guide.html

para los Estados promulgantes. Se reconoció que las dos opciones proporcionaban solamente una orientación no vinculante puesto que los Estados no estaban obligados a promulgar sus leyes sobre la base de los modelos de la CNUDMI y podían ajustar estos modelos a las circunstancias locales que considerasen apropiadas. Si bien la diferencia podría, en definitiva, residir solamente en los nombres de los instrumentos y las formas de presentarlos, no en su fondo o carácter, la forma representaría una considerable ventaja en la medida en que un modelo fácil de usar se tendría más en cuenta y su uso estaría más generalizado entre los encargados de formular políticas, legisladores y proveedores de asistencia.

64. En respuesta a la pregunta de por qué no se había preparado una ley modelo en 2003, se explicó que en esa época no había consenso sobre la definición de la colaboración público-privada y que no había gran demanda de una ley modelo puesto que la colaboración público-privada se consideraba un concepto normativo que no debía regularse por ley. Como ya se explicó en el capítulo II.A, estos factores cambiaron después de 2003.

4. Consideraciones que han de tenerse en cuenta en la organización de la labor de la CNUDMI en la esfera de la colaboración público-privada

65. Se afirmó que si se iba a realizar trabajo alguno en relación con la colaboración público-privada, sería esencial determinar qué prácticas de regulación de la colaboración público-privada eran las mejores o suficientemente buenas a fin de impartir un asesoramiento imparcial. La CNUDMI podría tropezar con dificultades a este respecto, dados los intereses creados y las instituciones que los representan, incluidos algunos consultores e instituciones financieras del sector privado. Por ejemplo, en los casos en que los asesores de los gobiernos para las reformas legislativas y proveedores de servicios de asistencia técnica y de creación de capacidad sean, al mismo tiempo, financiadores de la colaboración público-privada u operadores de proyectos, se plantearán inevitablemente conflictos de interés. Sería de igual importancia determinar cuáles son las prácticas deficientes, muchas de las cuales han sido adoptadas repetidamente por los consultores y asesores internacionales de los gobiernos.

66. Se alentó a la CNUDMI a aprovechar la considerable información sobre la colaboración público-privada acumulada por diversas instituciones, consistente en bases de datos sobre contratos, leyes de colaboración público-privada y otras leyes afines en todo el mundo; estudios de actividades de colaboración público-privada y los resultados de la evaluación del marco jurídico de la colaboración público-privada en varios países; y bases de datos sobre expertos, asesores, especialistas y coordinadores locales en materia de colaboración público-privada. También se destacaron las herramientas que permiten localizar los resultados de diversas operaciones de colaboración público-privada, el volumen de las inversiones, los aspectos de energía renovable y datos sobre las actividades de colaboración público-privada desglosados por sector.

67. Si bien también deberían consultarse, en cualquier posible labor de la CNUDMI en esta esfera, otros instrumentos internacionales y regionales que regulan diversos aspectos de la colaboración público-privada, se alentó a la Comisión a que no tratara de lograr la armonización entre todos esos instrumentos en vista de su alcance, orientación y finalidad diversos. La CNUDMI debería adoptar, en cambio, un espíritu crítico al examinar los distintos textos desde la perspectiva de su utilidad

para la labor (es decir, si habría algún valor añadido en utilizarlos como base para su labor o simplemente para fines de consulta). Se señaló que la labor de la CNUDMI en esta esfera podría requerir que esos otros instrumentos fueran actualizados o revisados.

68. Se insistió en la importancia de tener presentes los límites de lo que puede alcanzarse en un plazo razonable, teniendo en cuenta la complejidad de los problemas que se pretende abordar. Las opiniones variaban en cuanto al volumen de trabajo requerido. Algunos consideraron que la preparación de una ley modelo o de una guía ampliada no llevaría mucho tiempo, puesto que la mayoría de los problemas ya habían sido tratados en los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada, en tanto que otros opinaron que todavía quedaba mucho por hacer en cuanto a la actualización de los textos a fin de preparar una ley modelo. Si bien era cierto que el dar mayor claridad a los elementos básicos ya tratados en los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada no llevaría mucho tiempo, la adición de elementos nuevos y la necesidad de precisar mejor el alcance y la terminología exigirían un trabajo considerable. También se señaló que la preparación de un instrumento simple y breve -que debería ser el objetivo de la labor de la CNUDMI en esta esfera- era considerablemente más difícil que preparar un instrumento voluminoso y complejo. Se hizo hincapié en que la actual Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada debería reestructurarse y volver a redactarse en términos simples si se quería que fuera de utilidad para sus destinatarios.

69. Se subrayó que sería un foro intergubernamental (la Comisión y sus grupos de trabajo) el que se encargaría de elaborar cualquier texto que hubiera de preparar la CNUDMI. Los estudios y proyectos preliminares a cargo de la Secretaría serían esenciales para acelerar la labor del órgano intergubernamental. Sería necesario contar con la participación de expertos en la labor preparatoria de la Secretaría y asignar tiempo suficiente para esa labor si se quería elaborar estudios y proyectos de calidad adecuada.

70. Se observó también que las deliberaciones deberían ser lo más inclusivas y amplias posible para lograr una representación equilibrada de las opiniones y los intereses diversos y, por tanto, un resultado satisfactorio (sería necesaria, además de la participación de los Estados Miembros y Estados observadores, la de asociaciones profesionales, medios académicos y organizaciones de la sociedad civil). Debía velarse por el mantenimiento de una estrecha cooperación entre la CNUDMI y las instituciones internacionales y regionales que trabajaban en la esfera de la colaboración público-privada. El proceso de preparación de los textos permitiría a los especialistas locales y los expertos internacionales intercambiar ideas, conocimientos y experiencias a fin de llegar a un consenso sobre qué era lo que constituía las mejores prácticas internacionalmente aceptadas en la regulación de la colaboración público-privada.

71. Hubo acuerdo en que cualquier labor ulterior de la CNUDMI en esta esfera y los resultados que derivasen de esa labor serían de importancia para las actividades de asistencia técnica y de creación de capacidad local de la CNUDMI y otras entidades.

III. Conclusiones

72. Hubo acuerdo en que la colaboración público-privada se utilizaba cada vez más en todo el mundo, no solo como medio de movilización de recursos del sector privado para satisfacer necesidades públicas, sino también como medio de prestar mejores servicios al público, aprovechando la creatividad, las fuerzas innovadoras, los conocimientos especializados y las ventajas competitivas del sector privado. Se consideró que la colaboración público-privada constituía un mecanismo esencial para lograr el desarrollo sostenido y sostenible y contribuir a la mitigación de la pobreza, puesto que representaba una actividad conjunta del sector público y el privado, que, para tener éxito, debía tener en cuenta numerosas consideraciones, incluido el efecto directo del proyecto en los usuarios finales, los ciudadanos.

73. También se consideró que la colaboración público-privada sería ventajosa debido a la mayor eficiencia del sector privado, en comparación con el sector público, en el desarrollo y la ejecución de proyectos.

74. Se reconoció que la colaboración público-privada se había convertido en un concepto jurídico y había pasado a ser objeto de legislación en muchos países pero que, en vista de que el marco jurídico para regular esa actividad era inadecuado, la colaboración público-privada había fracasado en muchos casos. Un marco jurídico adecuado no resolvería todos los problemas, pero ofrecería un sistema con arreglo al cual podría emprenderse la colaboración público-privada. Sin embargo, establecer un marco jurídico adecuado no era una tarea fácil en vista de los complejos e intrincados problemas que debían resolverse.

75. Los esfuerzos nacionales encaminados a establecer un marco de este tipo se beneficiarían si se les prestara apoyo internacional en la forma de un modelo fácil de usar, que actualmente no existe. Los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada no pueden desempeñar esa función -pese a reconocerse que su contenido es excelente- debido a su alcance limitado y su volumen y complejidad, que los hacen útiles para los expertos y especialistas internacionales pero no para los encargados de formular políticas, los legisladores o los reguladores a nivel local. Además, la multiplicidad de directrices internacionales sobre la colaboración público-privada, no todas ellas coherentes, hacen aún más difícil la tarea de quienes procuran lograr la reforma jurídica.

76. Hubo acuerdo unánime en que, en vista de la evolución de la regulación de la colaboración público-privada y la experiencia en el uso de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada descritas en el capítulo II.A, la CNUDMI debería evaluar sus instrumentos sobre los proyectos de infraestructura con financiación privada para determinar cómo asegurarse de que sigan reflejando las mejores prácticas en la regulación de la colaboración público-privada. La opinión preponderante fue que el momento también era oportuno para que la CNUDMI procurase proporcionar a la comunidad internacional una ley modelo sobre la colaboración público-privada, acompañada de una guía detallada para su incorporación al derecho interno.

77. Esta tarea está de acuerdo con el mandato general de la CNUDMI y la función de la Comisión de determinar cuáles son las mejores prácticas en la regulación de una actividad comercial particular y preparar textos jurídicos que las reflejen de manera apropiada.

78. Las consideraciones relativas al tiempo que debería dedicarse al proyecto y al hecho de que no sería posible alcanzar la armonización en todos los aspectos de la colaboración público-privada, afectarán el alcance del proyecto. Si bien es cierto que la labor en esta esfera podría considerarse de carácter urgente y que, por tanto, debería realizarse lo antes posible, la magnitud de la empresa, si ha de ampliarse y precisarse el alcance de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada, no puede subestimarse.

79. La futura labor se basará en esos instrumentos de la CNUDMI y en los trabajos ya hechos, en particular porque muchas de las inquietudes sobre la experiencia en la práctica de la regulación y ejecución de la colaboración público-privada expresadas en el coloquio ya han sido encaradas en los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada. Queda por decidir si la orientación que contienen es suficientemente precisa y completa.

80. Debería difundirse la información sobre el contenido de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada para permitir la realización de un análisis crítico de ese tipo. El objetivo debería consistir en el reconocimiento de las lagunas y necesidades de mejora en estos instrumentos, las razones de las lagunas existentes (si se deben a una decisión deliberada, o a novedades o a la experiencia adquirida en la utilización de los instrumentos) y qué mejoras pueden hacerse, cómo y dentro de qué plazos, y qué lagunas subsistirían de todos modos y por qué. Se considera que un análisis exhaustivo de ese tipo es esencial para poder adoptar una decisión bien fundada sobre el alcance de la posible futura labor de la CNUDMI en la materia y el tiempo que podría exigir.

81. Se convino en que, en caso de considerarse que no había todavía consenso para elaborar una ley modelo con un número limitado de opciones para los Estados promulgantes, seguiría siendo de considerable valor para la comunidad internacional que continuara la labor con los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada en su forma actual.

82. La CNUDMI debería considerar la importancia, no solo del resultado alcanzado en última instancia con su labor en esta esfera, sino del proceso mismo que llevaría a ese resultado. No debe subestimarse el valor de la labor sugerida en párrafos anteriores en cuanto a la difusión de información sobre los instrumentos de la CNUDMI como herramientas de asistencia técnica y de creación de capacidad local. Estas actividades contribuirían también al cumplimiento de otro mandato de la CNUDMI: la coordinación de la labor de las organizaciones que desarrollan actividades en la esfera del derecho mercantil internacional y el fomento de la cooperación entre ellas. Es necesaria una estrecha coordinación y cooperación de las distintas instituciones y personas que participan en actividades legislativas, de asistencia técnica y de creación de capacidad en la esfera de la colaboración público-privada para poner fin a la tendencia actual a formular normas contradictorias, proporcionar asesoramiento poco consecuente y repetir los errores de prácticas equivocadas. Si bien será difícil o imposible de lograr la armonización por la CNUDMI de todos los textos existentes que proporcionan orientación sobre la colaboración público-privada, al preparar un patrón en esta esfera la CNUDMI alentaría a la comunidad internacional a empezar a hablar con una sola voz sobre las cuestiones de la colaboración público-privada.

83. A fin de velar por que el texto resultante sea universalmente aplicable en el contexto de las muchas entidades que son partes en la colaboración público-privada, la participación en las deliberaciones de un órgano intergubernamental debería ser lo más inclusiva posible y no deberían escatimarse esfuerzos para lograrlo.

84. Se consideró que sería útil que todo mandato para la labor futura en la esfera de la colaboración público-privada persiguiera los siguientes fines:

a) Formular un texto jurídico sobre la colaboración público-privada, consistente en una ley modelo (o, si eso no fuera posible, disposiciones legales modelo) acompañada de directrices normativas y prácticas;

b) Dejar suficiente margen para la flexibilidad, la innovación y la creatividad, lo cual facilitará la consecución del desarrollo sostenible y de los objetivos socioeconómicos conexos;

c) Extraer y condensar las mejores prácticas de los textos existentes y las actividades de colaboración público-privada, indicando las lagunas de los instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada, revisando los elementos que hayan perdido actualidad e incluyendo cuestiones que anteriormente no se prestaban a la regulación pero que ahora pueden regularse en vista de la maduración del mercado;

d) Abordar las disposiciones básicas aplicables a las formas más comunes de colaboración público-privada y considerar si se necesita una labor ulterior sobre otras formas de colaboración (como la formación de asociaciones y alianzas) o sectores específicos del mercado y si conviene excluir alguna forma de colaboración público-privada del alcance del texto jurídico sobre este tipo de colaboración;

e) Abarcar todo el ciclo vital de las actividades de colaboración público-privada, incluida la planificación y gestión de los proyectos;

f) Determinar si existen obligaciones internacionales importantes que puedan afectar la regulación nacional de la colaboración público-privada (por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción);

g) Analizar la medida en que procedimientos clave para garantizar la transparencia y la competencia, según se declara en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública¹⁰, deberían aplicarse a los procedimientos de la colaboración público-privada, a fin de promover los valores básicos del uso óptimo de los recursos y la eliminación de los abusos; y

h) Lograr el justo equilibrio entre el rigor analítico y el análisis empírico, por un lado, y un enfoque pragmático, por el otro, a fin de lograr la publicación oportuna de un texto de la CNUDMI sobre la colaboración público-privada que sea de utilidad práctica para los legisladores en países con distintos niveles de capacidad y experiencia en la materia.

¹⁰ *Ibid.*, Sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento número 17 (A/66/17), anexo I.

También puede consultarse en

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html.

C. Microfinanzas: creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas

(A/CN.9/780)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-5
II. Condiciones jurídicas propicias para las microempresas	6-48
A. Sinopsis	6-13
B. Modelos empresariales alternativos y simplificados en el contexto de las microfinanzas	14-18
C. Mecanismos eficaces de solución de controversias para microempresas y pequeñas y medianas empresas	19-27
D. Condiciones jurídicas propicias para los pagos mediante dispositivos móviles.	28-35
E. Cuestiones jurídicas relacionadas con el acceso al crédito de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas	36-43
F. Marco jurídico de la insolvencia y los procesos de liquidación de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas	44-48
III. Orientaciones para el futuro	49-55

I. Introducción

1. El tema de las microfinanzas viene figurando en el programa de la CNUDMI desde 2009, cuando la Comisión, en su 42º período de sesiones, pidió a la Secretaría que preparara un estudio detallado en el que se hiciera una evaluación de las cuestiones legales y reglamentarias suscitadas por las microfinanzas. El estudio debía presentarse acompañado de propuestas acerca de la forma y la naturaleza de un documento de consulta en que se examinaran los diversos elementos requeridos para establecer un marco legal favorable para el desarrollo de las microfinanzas, y que sirviera de base para que la Comisión estudiara en el futuro la conveniencia de preparar ese documento con miras a prestar asistencia al legislador y a otros órganos rectores competentes en diversas partes del mundo¹.

2. En el estudio, que se examinó en el 43º período de sesiones de la Comisión, celebrado en 2010, se analizaba la función que desempeñaban las microfinanzas en la mitigación de la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante la facilitación del acceso a servicios financieros de los pobres que no pueden valerse del sistema financiero estructurado. En el entendimiento de que un

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17).*

entorno normativo adecuado contribuiría al fomento del sector de las microfinanzas, la Comisión convino en que la Secretaría convocara un coloquio, en el que posiblemente participaran expertos de otras organizaciones que se ocupasen activamente del tema, con el cometido de estudiar las cuestiones jurídicas y reglamentarias relativas a las microfinanzas que entrasen en el mandato de la CNUDMI. Ese coloquio debía culminar en un informe oficial en el que se precisaran las cuestiones de interés y se enunciaran recomendaciones acerca de la labor que la CNUDMI podría llevar a cabo útilmente sobre el tema².

3. En el coloquio, celebrado en enero de 2011, se llegó a varias conclusiones³. A pesar de que se habían emprendido varias iniciativas exitosas en el plano nacional, no existía un conjunto coherente de medidas jurídicas y reglamentarias a nivel mundial que pudiera servir de estándar para las mejores prácticas internacionales. Muchos Estados tenían problemas para establecer un marco normativo adecuado que promoviera la inclusión financiera (el término más reciente aplicado a las “microfinanzas”), y se sugirió que la Comisión podría realizar una contribución sustantiva en tal sentido. Se señalaron varias cuestiones que podrían examinarse en el futuro, de las cuales, en su 44º período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión eligió las siguientes para que la Secretaría realizara un estudio a fondo: i) la captación en garantía de excesivos bienes o de bienes de poca cuantía económica; ii) el dinero electrónico y su conceptualización como una forma de ahorro; la conceptualización de la emisión de dinero electrónico como práctica bancaria a fines de su reglamentación y de la cobertura de los fondos así emitidos por el seguro de depósito bancario; iii) los procedimientos equitativos, rápidos, transparentes y poco costosos para la solución de controversias nacidas de operaciones microfinancieras; y iv) las medidas para facilitar a la pequeña y la mediana empresa y a la microempresa el recurso a prácticas de financiación garantizada, velando por su transparencia. En ese período de sesiones, la Comisión también decidió incluir las microfinanzas como tema de su labor futura⁴.

4. En el estudio de la Secretaría⁵, que se presentó en el 45º período de sesiones de la Comisión, celebrado en 2012, figura un breve resumen del estado en que se encuentra cada uno de los cuatro temas indicados precedentemente, así como las cuestiones jurídicas y reglamentarias fundamentales conexas, para su examen por la Comisión. Después de los debates, la Comisión convino unánimemente en celebrar con carácter prioritario uno o más coloquios sobre las microfinanzas y cuestiones conexas, haciendo especial hincapié en: la facilitación de la constitución y el registro simplificados de empresas; el acceso al crédito para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas; la solución de controversias aplicable a las operaciones microfinancieras; y otros temas relacionados con la creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas⁶.

² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17).*

³ Véase A/CN.9/727.

⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17).*

⁵ Véase A/CN.9/756.

⁶ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17).*

5. En la presente nota figuran las conclusiones más importantes del coloquio organizado por la Secretaría en Viena, del 16 al 18 de enero de 2013. El coloquio se estructuró en torno a una serie de ponencias y mesas redondas dedicadas a los temas siguientes: creación de condiciones propicias para las microempresas y estado de derecho; constitución y registro de microprestatarios; mecanismos eficaces de solución de controversias por vías alternativas; condiciones jurídicas propicias para los pagos mediante dispositivos móviles; cuestiones jurídicas relacionadas con el acceso al crédito de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas; e insolvencia y liquidación de microempresas. Entre los oradores y participantes hubo especialistas de gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado e instituciones académicas de todo el mundo.

II. Condiciones jurídicas propicias para las microempresas

A. Sinopsis

6. Aproximadamente la mitad de los trabajadores de todo el mundo están empleados en el sector no estructurado, que cada año mueve unos 10 billones de dólares de los Estados Unidos (es decir, la tercera parte de la economía mundial)⁷. Como dijo la Comisión para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres, estos trabajadores “... no funcionan dentro de la ley, sino fuera de ella: firman contratos de trabajo informales, manejan comercios no registrados y, a menudo, ocupan tierras sobre las que no poseen derechos formales”⁸. Entre las razones para operar en el sector no estructurado cabe mencionar las cargas fiscales, la regulación excesiva del sector estructurado, el deterioro de la calidad de los bienes públicos (por ejemplo, la infraestructura pública) y de la administración pública⁹, y la dinámica del sector estructurado. Sin embargo, los resultados no varían: las microempresas no pueden hacer cumplir sus contratos, obtener préstamos bancarios oficiales ni expandirse más allá de un ámbito local muy reducido¹⁰. En suma, no tiene muchas opciones “excepto desarrollar sus actividades comerciales en los sectores informales de la economía”¹¹.

7. Hay una serie de factores fundamentales para que las microempresas puedan ingresar al mercado estructurado y operar en él. Uno de los más importantes es su formalización, lo que incluye su constitución, la obtención de una licencia y el cumplimiento de otros requisitos registrales. Sin embargo, poner en marcha una empresa reconocida jurídicamente puede ser un proceso extremadamente oneroso. La tramitación a veces es muy costosa, y en algunos casos se exigen ciertos requisitos iniciales (por ejemplo, un capital mínimo), así como procedimientos administrativos engorrosos (por ejemplo, la presentación de numerosos documentos

⁷ Véase R. Neuwirth, *Stealth of Nations; The Global Rise of the Informal Economy*, 2011, pág. 27.

⁸ Informe de la Comisión para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres, *La ley: clave para el desarrollo sin exclusiones*, vol. I, 2008, pág. 17.

⁹ F. Schneider, A. Buehn, C. E. Montenegro, *Shadow Economies All over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007*, Banco Mundial, pág. 7.

¹⁰ Informe de la Comisión para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres, *La ley: clave para el desarrollo sin exclusiones*, vol. I, 2008, pág. 17.

¹¹ *Ibid.*, pág. 47.

diferentes con fines similares). Algunos de esos requisitos son reliquias de instituciones preexistentes, muchas de las cuales persisten esencialmente debido a grupos de presión que pueden entorpecer la reforma jurídica¹². Esos problemas desalientan a muchas microempresas y pequeñas y medianas empresas de proceder a su formalización.

8. Los microprestatarios a menudo no conocen sus derechos ni saben cómo protegerlos¹³. Además, el sistema de justicia formal tiende a excluirlos porque “no pueden permitirse contratar a un abogado, o pagar las costas judiciales ... los procedimientos judiciales pueden ser lentos, y es frecuente que los tribunales tengan un retraso considerable en la tramitación de las causas”¹⁴. Sin embargo, muy pocas veces se cuenta con mecanismos extrajudiciales de solución de controversias, lo que limita la eficacia de todo marco jurídico de las microfinanzas en lo que respecta a la protección al cliente. En consecuencia, 4.000 millones de habitantes de todo el mundo carecen de acceso a la justicia¹⁵.

9. En la actualidad, 2.700 millones de adultos de todo el mundo no tienen cuenta de ahorros o de crédito en un banco u otra institución oficial: esa cifra incluye los hogares, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, se calcula que aproximadamente 1.700 millones de personas de bajos ingresos sin acceso a los bancos tienen acceso a la telefonía móvil¹⁶, que, junto con otras nuevas tecnologías, les permite realizar operaciones financieras accesibles y fiables¹⁷. Sin embargo, para los encargados de formular políticas a nivel nacional, así como para los órganos encargados de establecer estándares a nivel mundial, esos nuevos modelos de prestación de servicios bancarios a quienes carecen de ellos resultan problemáticos porque implican la participación de nuevos agentes y la creación de nuevas relaciones entre los agentes. En el coloquio sobre microfinanzas celebrado por la Comisión en 2011 ya se señalaron varias cuestiones jurídicas sin resolver relacionadas con la naturaleza del dinero electrónico y se hizo referencia a la posibilidad de que tuvieran un efecto negativo en las personas de bajos ingresos¹⁸.

10. La mayoría de las empresas informales operan con apenas una cantidad limitada de capital familiar¹⁹. Al no tener acceso al sistema bancario tradicional, a menudo recurren a servicios de microfinanciación cuando necesitan fondos. Sin embargo, la comercialización cada vez mayor del sector, la intensa competencia entre las instituciones microfinancieras y el bajo nivel de conocimientos, incluso en asuntos financieros, que suelen tener los microprestatarios pueden dificultar considerablemente los retos que estos afrontan en su búsqueda de una financiación asequible. Por ejemplo, los microprestatarios a veces terminan pagando tipos de

¹² F. Reyes, *Latin American Company Law – A New Policy Agenda: Reshaping the Closely-Held Entity Landscape*, 2013, pág. 23.

¹³ Véase A/CN.9/727.

¹⁴ Véase A/CN.9/756, párr. 24.

¹⁵ Informe de la Comisión para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres, *La ley: clave para el desarrollo sin exclusiones*, vol. I, 2008, pág. 13; y A/CN.9/756, párr. 24.

¹⁶ Véase el sitio web del Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Más Pobre: www.cgap.org/topics/mobile-banking.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Véase A/CN.9/727, párrs. 43 y 44.

¹⁹ Informe de la Comisión para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres, *La ley: clave para el desarrollo sin exclusiones*, vol. I, 2008, pág. 62.

interés cinco o seis veces mayores que las empresas estructuradas, que tienen acceso a servicios bancarios y pueden conseguir condiciones más favorables para sus préstamos. Unas reformas jurídicas mediante las cuales se pudiera otorgar a los microprestatarios y pequeños prestatarios la condición de persona “jurídica”, con facilidad, previsibilidad y a bajo costo, pondría a esas personas en condiciones de actuar como prestatarios del sector “formal” o “estructurado” (véase el párrafo 7). En tal sentido, cabe señalar que una forma de registro comercial reconocida internacionalmente facilitaría el comercio transfronterizo de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas que operan en los mercados regionales, ya que aportaría un fundamento internacional reconocible para las operaciones y ayudaría a evitar los problemas que se pueden presentar en razón de la falta de reconocimiento de la formalidad comercial. El Banco Mundial ha determinado que las economías con sistemas modernos de registro comercial crecen más rápidamente²⁰, promueven una mayor iniciativa empresarial y productividad²¹, crean empleo²², impulsan la certeza jurídica²³ y atraen corrientes más grandes de inversión extranjera directas²⁴. Las reformas jurídicas también deberían hacer posible que los microprestatarios y pequeños prestatarios obtengan préstamos garantizados sin tener que aumentar su responsabilidad personal o la de sus familias o amigos, sino mediante el valor de mercado de sus activos.

11. No resulta sorprendente que las empresas informales a menudo tengan una vida muy breve²⁵, ya que las condiciones en que operan las hacen particularmente vulnerables a los cambios en el mercado y están más expuestas a la quiebra. Se ven afectadas por economías de escala reducidas, su riesgo en el proceso de constitución es mayor y les resulta difícil obtener financiación²⁶. Sin embargo, en la mayoría de los países no se cuenta con regímenes especiales eficaces de liquidación para esas empresas, lo que da lugar a que en algunos regímenes los empresarios con problemas financieros simplemente cierren y se vayan, mientras que en otros a veces deben afrontar batallas contra sus acreedores que durarán toda la vida²⁷. Unas reformas jurídicas adecuadas, que se ajusten a las necesidades de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, permitirían a las empresas viables recuperarse y seguir funcionando.

12. A fin de ayudar a que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas puedan adaptarse a la falta de certeza inmediata y pasar de una forma de funcionar basada en la subsistencia al modo de crecimiento característico del sector estructurado, hay que crear condiciones jurídicas propicias. Ese tipo de entorno no se limita únicamente a las microfinanzas; está relacionado con el ciclo vital de la empresa: su constitución, funcionamiento y cierre, y también se debe prestar atención al marco jurídico e institucional de apoyo. No obstante, es claramente pertinente para las microfinanzas, ya que por tratarse de un criterio basado en el

²⁰ Banco Mundial, IFC, *Doing Business 2013, Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises*, pág. 21.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, nota 16, pág. 25.

²³ *Ibid.*, pág. 21.

²⁴ *Ibid.*, pág. 14.

²⁵ Informe de la Comisión para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres, *op. cit.*, pág. 63.

²⁶ M. Uttamchandani, A. Menezes, *The Freedom to Fail: Why Small Business Insolvency Regimes are critical for Emerging markets*, *Economist's Outlook*, 2010, pág. 263.

²⁷ *Ibid.*, pág. 262.

mercado para luchar contra la pobreza, las microfinanzas se centran en el fomento de la iniciativa empresarial y en ampliar el autoempleo²⁸. Además, las condiciones jurídicas propicias no deben limitarse únicamente a las microempresas. Como las definiciones de microempresa y pequeña empresa varían sustancialmente según la región y de un país a otro²⁹, los mismos factores que definen las condiciones jurídicas propicias deben aplicarse tanto a las microempresas como a las pequeñas y medianas empresas.

13. La creación de condiciones jurídicas propicias también contribuye a reforzar el estado de derecho a nivel de los países, lo que, como destacó la Asamblea General en su resolución sobre el estado de derecho³⁰, permite el crecimiento de un sistema justo, estable y previsible para generar un desarrollo inclusivo, sostenible y equitativo. Vale la pena señalar que recientemente la Asamblea General, una vez más “reconociendo la importante contribución que puede aportar la iniciativa empresarial al desarrollo sostenible”³¹, alentó “a los gobiernos ... a elaborar políticas ... que eliminen los obstáculos jurídicos, sociales y reglamentarios a la participación igual y efectiva en la economía y... [fomenten] la iniciativa empresarial”. Ese llamamiento también se amplió a la comunidad internacional, a la que se alentó “a apoyar los esfuerzos de los países por promover la iniciativa empresarial y fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y microempresas”³².

B. Modelos empresariales alternativos y simplificados en el contexto de las microfinanzas

14. El eurobarómetro de 2012 sobre el emprendimiento nos informa de que la gran mayoría de quienes en la Unión Europea respondieron a la encuesta sobre emprendimiento en la Unión Europea y más allá considera que es difícil poner en marcha una empresa propia en razón de la escasa disponibilidad de apoyo financiero (79%) y lo complejo del proceso administrativo (72%)³³. Aproximadamente el 67% de los encuestados considera que el autoempleo no una opción viable, y la impresión sobre la viabilidad del autoempleo desciende incluso al 19% en uno de

²⁸ A/CN.9/727.

²⁹ La inexistencia de una definición clara es el principal problema para asegurar la financiación de las pequeñas y medianas empresas; véase Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre, Financial Access Report 2010, pág. 37, que también incluye varias definiciones de pequeña y mediana empresa. Se puede encontrar una definición de pequeña y mediana empresa y de microempresa en la recomendación de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003 (2003/361/CE), y en Microenterprise Results Reporting: Methodology and Statistical Annexes FY 2010 19, U.S.AID, que se puede consultar en:

www.usaid.gov/our_work/economic_growth_and_trade/micro/MRR_FY10_Methodology__Statistical_Annexes_82211_Final.pdf. También hay distintas definiciones de microcrédito; véase, por ejemplo, Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, Microfinance activities and the Core Principles for Effective Banking Supervision, agosto de 2010, págs. 34 y 35.

³⁰ Véase A/RES/67/97.

³¹ Véase A/RES/67/202.

³² *Ibid.*

³³ 2012 Flash Eurobarometer on Entrepreneurship, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figuresanalysis/eurobarometer/index_en.htm, pág. 13.

los países encuestados. Los resultados en un grupo escogido de países que no pertenecen a la Unión Europea son muy similares: en 11 de los 13 países encuestados la mayoría afirma que el autoempleo no es viable (las dos excepciones son el Brasil y China). La debilidad del marco jurídico, o incluso su inexistencia tiene una clara influencia sobre la percepción de las personas respecto de lo que supone poner en marcha una empresa.

15. Es necesario que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas operen con arreglo a un modelo comercial reconocido a fin de atraer inversiones y proteger los intereses de los empresarios. Sin embargo, los modelos comerciales “tradicionales”, incluidas las sociedades comerciales y otros tipos de asociaciones civiles, pueden presentar obstáculos a su establecimiento. Esos modelos a menudo no se adaptan al propósito de las microempresas y las pequeñas empresas, ya que su establecimiento: a) es muy oneroso (tanto en dinero como en tiempo); b) dan lugar a una regulación excesiva (con altos costos de cumplimiento); y c) exponen al empresario a un importante riesgo por concepto de responsabilidad (véase también el párrafo 7).

16. Como respuesta a esta necesidad de contar con nuevas formas de entidades de responsabilidad limitada se están ideando nuevas formas de sociedad, incluidas formas comerciales híbridas, que facilitan la creación y el funcionamiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en la India, las asociaciones de responsabilidad limitada combinan las características de una sociedad comercial (al establecer la limitación de la responsabilidad) y de las asociaciones civiles (a los fines impositivos y de financiación). Una asociación de responsabilidad limitada se puede constituir rápidamente, por intermedio de un portal en la web, y su costo es muy reducido. En Colombia, la importante labor de reforma jurídica realizada en los últimos 15 años ha dado lugar a la creación de una forma comercial híbrida que da prioridad a la flexibilidad, la libertad contractual y la limitación de la responsabilidad: la llamada sociedad por acciones simplificada (SAS). La SAS puede estar integrada por uno o más socios y se puede constituir por medio de un documento privado o electrónico relativamente simple, a un costo mínimo. La ley de 2008 por medio de la cual se creó la sociedad por acciones simplificada se basa en un sistema de regulación *ex post*, con estándares ejecutables durante el funcionamiento (en vez de una regulación *ex ante*, que establece normas que se deben satisfacer durante la constitución), a fin de hacer frente a las conductas abusivas, con lo cual se reducen los costos para el establecimiento de microempresas. De hecho, el cumplimiento de requisitos estrictos para establecer una empresa, por ejemplo, el capital mínimo legal o los documentos públicos de constitución, afecta a todos los empresarios. Por otra parte, cuando se aplican estándares que se pueden ejecutar *ex post* (por ejemplo, normas sobre abuso de derecho o tratamiento equitativo, que dan discreción a las autoridades judiciales para determinar *ex post* si se ha cometido una violación), el costo solo existe para los empresarios que no respetan los estándares. No obstante, este criterio exige una infraestructura judicial eficaz para supervisar y hacer cumplir los estándares *ex post*. Desde que en 2008 se promulgó la ley por medio de la cual se creó la SAS se han establecido unas 181.742 empresas de este tipo (los datos se refieren a noviembre de 2012), y se estima que en la mayoría de ellas eran empresas que operaban anteriormente en el sector no estructurado. Las SAS representan más del 95% de la participación en el mercado y, según datos de 2009-2010, han permitido que el

crecimiento de las entidades comerciales del sector estructurado haya superado el 25%.

17. La legislación elaborada por el Gobierno de Colombia se inspiró en la de Francia, entre otros países. En Francia, las estructuras societarias especiales permiten a los empresarios separar de manera efectiva los bienes personales de los de la empresa, ya sea por la forma de la estructura misma, por ejemplo la empresa unipersonal de responsabilidad limitada (EURL) o la empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL), ya sea mediante una declaración de bienes inembargables. Esos criterios dan flexibilidad al empresario y también ofrecen una mejor información al posible acreedor. En Alemania, los legisladores decidieron no crear una nueva estructura jurídica, sino facilitar el ingreso al reducir de manera considerable el capital inicial exigido (1 euro, en lugar de 25.000 euros) y reducir otros costos de constitución facilitando un protocolo modelo y estableciendo tarifas notariales y de registro bajas. En los 12 meses posteriores a la reforma legislativa (1 de noviembre de 2008 a 1 de noviembre 2009) se registraron 19.563 empresas; a enero de 2013, ese número había aumentado a 76.377. Otro ejemplo que cabe mencionar es la experiencia de Angola de facilitar las microempresas mediante la creación de la Oficina de Única del Empresario, que ha hecho hincapié en la necesidad de: a) simplificar el proceso de constitución; b) acelerar la concesión de permisos para operar una empresa; y c) reducir las tarifas de constitución. En el Brasil, los problemas que, a pesar de varias oleadas de reforma, dificultan el logro de un mejor régimen societario para las empresas más pequeñas han llevado a reflexionar sobre la asistencia que los estándares internacionales en esa esfera (que actualmente no existen) podrían aportar para modificar el *statu quo*.

18. Debe señalarse que la mayoría de las reformas mencionadas son relativamente recientes (del último decenio) y que en muchas jurisdicciones todavía hay problemas para encontrar una solución normativa adecuada. Entre las características comunes para facilitar la participación de las microempresas cabe mencionar la necesidad de establecer estructuras societarias flexibles, simplificadas y de bajo costo, acompañadas de directrices claras y con el apoyo de una infraestructura administrativa y judicial simplificada y eficaz.

C. Mecanismos eficaces de solución de controversias para microempresas y pequeñas y medianas empresas

19. Se ha determinado que la solución de controversias es uno de los elementos que definen el vigor del marco institucional de un país respecto de las microfinanzas (otro elemento fundamental es la regulación transparente de los precios)³⁴. Sin embargo, según se destacó en un estudio reciente, los mecanismos de solución de controversias se caracterizan a menudo por el difícil acceso y la ineficacia, lo que sugiere que es necesario hallar nuevas soluciones para alentar mecanismos adecuados de microfinanciación³⁵.

20. Entre tanto, la industria de las microfinanzas se ha valido esencialmente de la autorregulación, que, por sí sola, no basta para proteger eficazmente a los clientes.

³⁴ Economist Intelligence Unit, Global microscope on the microfinance business environment 2012, pág. 23.

³⁵ *Ibid.*

Si bien las instituciones financieras constituyen la primera línea de defensa en lo que respecta a la solución de controversias³⁶, se ha señalado que solo un pequeño número de países exige a las instituciones financieras que pongan en práctica procedimientos para atender las quejas de los clientes, establecer plazos oportunos de respuesta y asegurar el acceso³⁷. Ello corrobora la opinión de que es probable que las quejas se resuelvan mejor mediante mecanismos de autorregulación si los clientes también tienen acceso a sistemas externos para resolver controversias.

21. Según la situación de cada país, esos sistemas podrían incluir procedimientos judiciales simplificados, mediación y arbitraje comerciales acelerados u oficinas de defensoría para cuestiones financieras. También se podría incluir más de un mecanismo, ya que estos no se excluyen mutuamente³⁸.

22. En las respuestas de los Estados al cuestionario sobre microfinanzas que la Secretaría distribuyó en 2011 a solicitud de la Comisión³⁹ se indica que, en algunos casos, se han establecido tribunales para causas de menor cuantía, por ejemplo en Israel, Filipinas y algunos estados de los Estados Unidos. Otros países han establecido servicios de defensoría o instituciones especializadas para la solución de controversias dimanadas de reclamaciones financieras. Sin embargo, no todos estos sistemas (ya sean de defensoría, de arbitraje o de otro tipo) están autorizados a dictar resoluciones vinculantes. Algunos sistemas se basan más en el cumplimiento voluntario por la parte que cometió la falta: por ejemplo, en Italia, si la institución financiera no cumple la decisión del *árbitro bancario financiero*⁴⁰, se hace pública la notificación de incumplimiento.

23. Trinidad y Tabago, uno de los pocos países de bajos ingresos que cuenta con una defensoría para cuestiones financieras, ha establecido una oficina de ese tipo sobre la base de la participación voluntaria⁴¹. La oficina no solo ofrece servicios de mediación gratuitos a los clientes de bancos y empresas aseguradoras (personas físicas o pequeñas empresas), sino que también promueve la adquisición de conocimientos financieros básicos entre los posibles clientes, utilizando distintos procedimientos formales e informales. La experiencia de la oficina ha resultado satisfactoria, si bien ha quedado de relieve la importancia de consagrar esos regímenes en la ley, a fin de evitar que quede fuera de la jurisdicción de la defensoría una gran cantidad de reclamaciones (debido a la falta de voluntad de algunos proveedores de servicios financieros participantes en el plan). Por ejemplo, el mandato de la oficina no incluye las quejas relativas a las políticas generales sobre tipos de interés o la determinación de los precios de productos o servicios. Además, si se diera carácter legislativo al sistema de defensoría, también se facilitaría la introducción de las sanciones correspondientes para los casos de incumplimiento⁴².

³⁶ Véase Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre, *Financial Access Report 2010*, pág. 31.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17)*, párr. 246.

⁴⁰ El título se puede traducir como “árbitro bancario financiero”. Sin embargo, sus funciones no se pueden comparar a las de un árbitro en un procedimiento arbitral.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Office of the Financial Services Ombudsman, *Annual Report 2011*, Trinidad y Tabago, pág. 8.

24. En general, la legislación sobre los mecanismos de solución de controversias por vías alternativas aplicables a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas aparentemente no está muy difundida. Por ejemplo, solo recientemente se ha promulgado en Colombia una nueva ley de arbitraje⁴³ que establece que los centros de arbitraje deben ofrecer procedimientos de arbitraje gratuitos para los casos de menor cuantía (aproximadamente hasta 13.000 dólares). Esos procedimientos deben ser breves y no es necesario que las partes estén representadas por letrados. El Ministerio de Justicia promulgará reglamentación que establezca el número mínimo de procedimientos de arbitraje gratuitos que los centros de arbitraje deberán ofrecer anualmente. La nueva ley también hace posible utilizar mecanismos en línea en todas las etapas del procedimiento de arbitraje y con cualquier propósito, a fin de reducir los costos administrativos. Otra novedad derivada de esta ley es el reglamento que Colombia está preparando sobre solución de controversias en línea, cuyo objeto es resolver las controversias de menor cuantía, incluidas aquellas en que participan microempresas y pequeñas empresas. Antes de esta reciente ley de arbitraje, la Cámara de Comercio de Bogotá respaldaba el fomento del arbitraje para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas y ofrecía procedimientos gratuitos para las controversias en que una de las partes fuera una empresa de ese tipo. Las normas de arbitraje de la Cámara también establecían un procedimiento con un árbitro único, cuya decisión debía emitirse en el plazo máximo de un mes (que podía prorrogarse por un mes más). Se estima que en los cuatro últimos años unas 300 microempresas y pequeñas y medianas empresas utilizaron ese servicio⁴⁴. También en Colombia, en el decenio último, el banco Caja Social puso en práctica un proyecto piloto de conciliación a fin de poder recuperar los préstamos de menor cuantía debidos por sus clientes, proceso que se sumó a los métodos tradicionales de las agencias de cobro y los litigios judiciales. Una vez finalizado el proyecto piloto, el banco determinó que el mecanismo de conciliación le había permitido recuperar sumas mucho mayores que los otros dos métodos, es decir, las agencias de cobro y los litigios judiciales⁴⁵.

25. Otros países han percibido la necesidad de promulgar leyes (o reglamentos) sobre mecanismos de solución de controversias por vías alternativas aplicables a la microfinanciación. Por ejemplo, en Nigeria los bancos de microfinanciación del estado de Lagos han pedido la creación de un tribunal especial para tramitar los casos de impago de préstamos, petición que a lo que aceptó el Banco Central de Nigeria en 2011. El tribunal todavía no se ha establecido, aunque actualmente el Banco Central está respaldando dos proyectos de ley que tienen una vinculación directa con el mejoramiento de la solución de controversias: el proyecto de ley sobre la defensoría para cuestiones financieras, que ayudaría a resolver más rápidamente las controversias financieras, y el proyecto de ley sobre mecanismos de

⁴³ Ley 1563/2012, 12 de julio de 2012; se puede consultar en:

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_1563_2012.htm.

⁴⁴ Véase Portafolio.co, Nueva Ley de Arbitraje, 10 de octubre de 2012; se puede consultar en:

<http://www.portafolio.co/opinion/nueva-ley-arbitraje>.

⁴⁵ A. Álvarez, *The private sector approach to commercial ADR: commercial ADR mechanisms in Colombia*, 2010, se puede consultar en:

https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/Private%20Sector%20Approach%20to%20Commercial%20ADR_%20the%20case%20of%20Colombia%20.pdf

solución de controversias por vías alternativas, que promovería y regularía esos mecanismos en Nigeria⁴⁶.

26. Los mecanismos de solución de controversias por vías alternativas quizás también puedan contribuir sustancialmente a resolver controversias distintas de las que se presentan más comúnmente en el ámbito de la microfinanciación. La Corporación Financiera Internacional ha señalado que cuando las estructuras de solución de controversias por vías alternativas son eficientes, pueden ser el medio más eficaz para recuperar los activos garantizados⁴⁷, y ello se podría aplicar en el contexto de los préstamos garantizados a los microprestatarios. La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, preparada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), establece explícitamente que se podrá utilizar ese tipo de mecanismos para solucionar todo tipo de controversias, incluidas las relacionadas con la ejecución (véase el artículo 68). Colombia está modernizando su marco legislativo para las operaciones garantizadas, y el proyecto de ley incluye una disposición sobre los mecanismos de solución de controversias vías alternativas basado en la Ley Modelo de la OEA.

27. Los ejemplos mencionados precedentemente indican que un marco jurídico eficaz para la solución de controversias destinado a los usuarios de las microfinanzas exigiría leyes y reglamentos que rijan las relaciones entre los proveedores de los servicios y los usuarios y que asegure la equidad, la transparencia y el derecho a recursos procesales⁴⁸. Un sistema de ese tipo promovería el acceso, tanto mediante mecanismos de recursos con arreglo a los procedimientos internos de las instituciones financieras como mediante mecanismos de solución de controversias por otras vías a cargo de terceros. La facilitación del acceso a esos mecanismos también incluye la posibilidad de que los reclamantes puedan presentar sus quejas en su propio idioma, gratuitamente o a costo reducido, y que existan puntos de fácil acceso al sistema⁴⁹. Un régimen jurídico eficaz para las microfinanzas aseguraría la ejecución de las decisiones pronunciadas en la mediación, los procesos de arbitraje o por conducto de una defensoría. Por último, un sistema de esa naturaleza promovería la capacidad y los conocimientos financieros, al ayudar a los usuarios de los servicios financieros a adquirir los conocimientos y las capacidades necesarios para gestionar sus finanzas⁵⁰.

⁴⁶ Economist Intelligence Unit, *Global microscope on the microfinance business environment* 2012, pág. 59.

⁴⁷ Corporación Financiera Internacional, *Secured Transactions Systems and Collateral Registries*, enero de 2010, pág. 54; se puede consultar en <https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/SecuredTransactionsSystems.pdf>.

⁴⁸ O. P. Ardic, J. A. Ibrahim, N. Mylenko, *Consumer Protection Laws and Regulations in Deposit and Loan Services: A Cross-Country Analysis with a New Data Set*, Banco Mundial, Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre, enero de 2011, pág. 2.

⁴⁹ Véase también Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre, *A Guide to Regulation and Supervision of Microfinance*, Consensus Guidelines, octubre de 2012, pág. 59.

⁵⁰ O. P. Ardic, J. A. Ibrahim, N. Mylenko, *Consumer Protection Laws and Regulations in Deposit and Loan Services: A Cross-Country Analysis with a New Data Set*, Banco Mundial, Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre, enero de 2011, pág. 2.

D. Condiciones jurídicas propicias para los pagos mediante dispositivos móviles

28. Se ha determinado que la banca sin sucursales⁵¹ (de la cual forman parte los pagos mediante dispositivos móviles) constituye un medio eficaz para lograr la inclusión financiera, ya que facilita el acceso a servicios financieros de manera conveniente y económica. Habida cuenta del alto nivel de penetración del acceso a la telefonía móvil en muchos países de todo el mundo (por ejemplo, en el Pakistán hay 110 millones de usuarios de teléfonos celulares pero solo 15 millones de usuarios de cuentas bancarias, y 400.000 agentes de telecomunicaciones en comparación con solo 12.700 sucursales bancarias), la tecnología es un medio eficaz para prestar ese tipo de acceso. Entre las ventajas de la banca sin sucursales, ya sea por conducto de teléfonos móviles o por otro tipo de arreglos, cabe mencionar las siguientes: mejoramiento del acceso de las personas que viven en zonas remotas; operaciones de bajo costo; mejoramiento de la eficiencia para los clientes y los proveedores de servicios; y menores pérdidas de fondos (a resultas de la reducción en el número de operaciones en efectivo).

29. Se cree que en la actualidad hay unos 50 modelos de pago mediante dispositivos móviles, con un amplio espectro de marcos normativos y de prácticas. Por ejemplo, en Kenya, a fin de contar con un marco normativo adecuado, Safaricom se vale de una combinación de leyes vigentes y modificadas y de la creación de nuevas leyes. Los principios rectores del marco legislativo de ese país incluyen la eficiencia y la accesibilidad (alentar el acceso de los clientes a los servicios financieros, reducir los obstáculos para el ingreso de nuevos participantes), la protección del cliente (la responsabilidad al respecto debe recaer en el proveedor del servicio y se deben incluir procedimientos accesibles y eficaces y vías de solución de las consultas o quejas de los clientes) y la neutralidad tecnológica (el marco normativo permite las transferencias electrónicas cualquiera sea la tecnología subyacente empleada).

30. En el Perú se promulgó recientemente una nueva Ley del dinero electrónico⁵², en la que se define al dinero electrónico como un valor monetario almacenado en un soporte electrónico, ampliamente aceptado como medio de pago, convertible a dinero en efectivo y que no se constituye depósito. La nueva ley trata de garantizar la seguridad, transparencia y fiabilidad para los clientes, así como alentar la competencia y la innovación entre las empresas. Con ese fin, solo permite la prestación de servicios basados en el dinero electrónico a las entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, intermediarios financieros ya incluidos en el mercado y las empresas que pueden ingresar al mercado como emisores especializados en dinero electrónico. La nueva ley se complementa con un marco jurídico amplio que ya estaba vigente en el momento en que se promulgó la ley y que, entre otras cosas, incluye los sistemas de pago, sistemas contra el blanqueo de dinero, regulación

⁵¹ Por banca sin sucursales se entiende en general la prestación de servicios financieros fuera de las sucursales bancarias convencionales, utilizando agentes o terceros intermediarios como interfaz principal con los clientes y empleando la tecnología (terminales de punto de venta y teléfonos móviles) para transmitir los detalles de las operaciones.

⁵² La Ley núm. 29985 fue aprobada por el Congreso el 12 de diciembre de 2012 y publicada el 17 de enero de 2013.

integral y riesgos operacionales, auditorías internas y regulación de los agentes minoristas. El propósito más importante de la ley es impulsar la inclusión financiera; en consecuencia, se espera que en los reglamentos subsidiarios de la ley, que serán promulgados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se defina una “cuenta” simplificada de dinero electrónico, similar al concepto de cuenta básica de depósito que ya está contemplado en la legislación del Perú. Se trata de un producto de bajo riesgo con requisitos de contratación mínimos, a saber, un documento nacional de identidad válido a fin de poder abrir una cuenta ante un agente minorista. Se aplican límites mensuales y diarios al saldo y al número de operaciones de este tipo de cuentas.

31. En Sri Lanka, las Directrices para los pagos mediante dispositivos móviles⁵³ promueven la seguridad y la eficacia de los servicios de pago móvil y aumentan la confianza de los usuarios. Las directrices obligan a los proveedores de servicios autorizados a adherirse a todas las leyes aplicables, incluida la Ley de operaciones electrónicas núm. 19, de 2006. Esa ley incluye disposiciones que reconocen las operaciones móviles como operaciones electrónicas jurídicamente válidas, con lo que se facilita la transición a ese tipo de comercio. La ley está muy influida por los textos de la CNUDMI (entre ellos la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, de 1996, y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, de 2005).

32. A pesar de la amplia gama de marcos normativos y prácticas, de los cuales los mencionados precedentemente no son más que unos pocos ejemplos, parece haber un consenso cada vez mayor con respecto a ciertos principios que son fundamentales para el desarrollo de la legislación sobre los pagos mediante dispositivos móviles, entre ellos: el uso de agentes por bancos y entidades no bancarias que emiten dinero electrónico; la regulación de los emisores de dinero electrónico; la protección del “fondo de caja” (es decir, los fondos públicos que el emisor de dinero electrónico tiene en su poder en la forma de dinero electrónico) de los emisores de dinero electrónico que no son bancos⁵⁴; y la protección financiera del cliente, por nombrar algunos. Entre las preocupaciones de reciente aparición cabe mencionar la interoperabilidad entre los distintos sistemas de banca sin sucursales; la competencia y el acceso justo a los sistemas de pago y a la infraestructura de comunicaciones; y la seguridad de los datos.

33. En consecuencia, un entorno jurídico propicio para los pagos mediante dispositivos móviles debe crear condiciones para tratar esas cuestiones y, al mismo tiempo, promover las innovaciones, alentar una entrada y salida fluidas en el mercado por los distintos interesados y facilitar el desarrollo sostenible del mercado. Las condiciones jurídicas deben ser dinámicas, adaptarse y evolucionar a medida que el mercado pasa por distintas etapas. Inicialmente se debe prestar atención a facilitar la innovación mediante la eliminación de obstáculos para el ingreso y asegurando la igualdad de condiciones para todos, y ofreciendo estándares jurídicos iguales para los distintos participantes dedicados a la misma actividad. A medida que se ponen en práctica las innovaciones, el entorno debe pasar a mitigar los

⁵³ Directrices para los pagos mediante dispositivos móviles núms. 1 y 2, de 2011, promulgadas de conformidad con el reglamento de la Ley sobre sistemas de pago y liquidación núm. 28, de 2005.

⁵⁴ Véase Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre, *A Guide To Regulation and Supervision of Microfinance*, Consensus Guidelines, octubre de 2012, pág. 77.

riesgos operacionales y mejorar la protección del cliente. A medida que se produce la consolidación, se vuelven más pertinentes la regulación prudente y las medidas contra los riesgos sistémicos. Un mercado maduro debe seguir siendo competitivo y eficaz a fin de lograr una mayor productividad.

34. Se pueden determinar varios componentes para la creación de condiciones propicias para los pagos mediante dispositivos móviles, entre ellos definiciones precisas de conceptos fundamentales como “depósito”, “pago” y “dinero electrónico”, que permitirán aportar claridad y uniformidad en la interpretación. La coordinación entre los organismos reguladores sería importante para garantizar un entorno normativo coherente, incluida la elaboración de estrategias de reglamentación y mitigación del riesgo tecnológico antes de poner en marcha los servicios de dinero electrónico. Además, el desarrollo de una estructura de mercado competitiva alentaría las innovaciones, eliminaría los obstáculos al ingreso y reduciría los costos. Se deben crear entidades nuevas prudentemente supervisadas a fin de gestionar el dinero electrónico. Idealmente, esas entidades de estructura de capital deben permitir que ingresen al mercado todo tipo de proveedores de servicios. No se debe subestimar la protección del cliente: las pérdidas relacionadas con los pagos mediante dispositivos móviles deben ser soportadas por los proveedores del servicio: los países en donde los agentes de telecomunicaciones son quienes ofrecen directamente los servicios financieros móviles deben considerar la promulgación de reglamentación separada a fin de determinar las responsabilidades de sus agentes.

35. Las condiciones jurídicas para los pagos mediante dispositivos móviles también deben tener en cuenta que ese tipo de pagos se encuentra en la intersección de dos esferas establecidas del derecho internacional: las operaciones electrónicas y los pagos internacionales. Los instrumentos vigentes de la CNUDMI, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico y la Ley Modelo sobre transferencias internacionales de crédito aportan la base necesaria para la elaboración de normas sobre los pagos mediante dispositivos móviles. A medida que la Comisión siga elaborando nuevas directrices relativas al tema, se debería considerar la posibilidad de establecer directrices en coordinación con otros órganos dedicados a la elaboración de normas en lo que respecta a la banca sin sucursales.

E. Cuestiones jurídicas relacionadas con el acceso al crédito de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas

36. Las empresas de todo el mundo han determinado que uno de los principales obstáculos que afrontan es el acceso al crédito. Ello es particularmente cierto en el caso de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Unos buenos sistemas de información sobre los antecedentes de crédito y unas leyes sólidas sobre garantías ayudan a superar ese obstáculo⁵⁵. En el caso de las microfinanzas y las microempresas, también son importantes las disposiciones relativas a la transparencia en las condiciones de los préstamos, las garantías excesivas y las

⁵⁵ Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional, Doing Business 2013, Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, pág. 22.

prácticas de cobro abusivas. Es importante aclarar que la transparencia en los préstamos no es una cuestión relacionada con la regulación prudente (que se refiere más bien a la seguridad y solidez de la aceptación de los depósitos y la regulación de los riesgos sistémicos en la macroeconomía). Más bien, es un concepto relacionado con los derechos del cliente y su protección y, por ello, es pertinente para el derecho mercantil.

37. Hay pruebas considerables de que muchas instituciones de microfinanciación fijan los precios de sus productos de manera poco transparente, oscureciendo el precio verdadero de los préstamos y confundiendo a los clientes mediante técnicas como la aplicación de tipos de interés “fijos” y unas complejas estructuras tarifarias. Un proceso de “espiral descendente” hace que las instituciones de microfinanciación responsables empleen esas prácticas a fin de poder competir, porque los precios transparentes parecen más onerosos que los que no lo son, aun cuando el producto ofrecido sea el mismo. El hecho de que en muchos países no exista legislación que obligue a divulgar las verdaderas condiciones de crédito ha permitido perpetuar esa situación, lo que ha dado lugar a mercados no transparentes, no competitivos y disfuncionales, en donde la falta de competencia en los precios permite que algunas instituciones obtengan beneficios altísimos a costa de las personas más pobres de la sociedad. Cuando se informa de las verdaderas condiciones de los créditos que se conceden se utilizan tasas porcentuales anuales o tasas de interés efectivo a fin de comparar el costo verdadero de los distintos tipos de préstamo. Las tasas porcentuales anuales y las tasas de interés efectivo son tasas anuales estandarizadas, que permiten que el prestatario conozca el costo real del préstamo. Para que esas tasas sean más exactas desde el punto de vista del cliente, no solo se debe incluir el tipo de interés, sino también otras tarifas obligatorias (por ejemplo, tarifas de capacitación, seguro y depósito de garantía), lo que permite al prestatario adoptar una decisión con conocimiento de causa.

38. Los datos sobre la fijación de precios transparentes obtenidos de 59 instituciones de microfinanciación de Filipinas demuestran que en las microfinanzas existe una “curva de precios”. Los préstamos de monto más reducido tienen los precios más altos debido a la correlación con los costos de funcionamiento más altos de las instituciones que ofrecen esos préstamos. Es necesario tener en cuenta esa curva cuando se aborda la eficacia de los límites máximos de los precios regulados⁵⁶ en la microfinanciación, una característica común de los entornos de regulación de las microfinanzas (por ejemplo, en la India, Colombia y la región de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental). Una consecuencia no prevista de esos límites es que pueden dar lugar a que se reduzca la oferta de los préstamos de menor cuantía (los que típicamente están destinados a los sectores más excluidos financieramente de la sociedad), ya que esos préstamos no se pueden ofrecer de manera sostenible si no se aplican precios más altos, mientras que los micropréstamos más grandes se pueden ofrecer a precios por debajo del límite y, sin embargo, resultar beneficiosos para los prestamistas. En consecuencia, la solución tan frecuentemente promovida de introducir límites máximos en los tipos de interés

⁵⁶ El “límite máximo en los precios” es un concepto más inclusivo que el “límite máximo en los tipos de interés”. Puede incluir otros costos, como tarifas de tramitación y, en ocasiones, el costo de otros servicios que se adjuntan al préstamo, como seguros; véase, por ejemplo, www.mftransparency.org/zambias-new-price-cap-good-intentions-with-unintended-consequences/.

puede resultar ineficaz si los precios no son transparentes. En general, un régimen no transparente de fijación de precios introduce en el mercado graves imperfecciones y confusión, que afectan por igual a consumidores, instituciones de microfinanciación, inversionistas y autoridades reguladoras.

39. En consecuencia, la transparencia es fundamental y la autorregulación en esa esfera no ha sido suficiente para proteger a los clientes, a pesar de los esfuerzos hechos por la industria, como la campaña mundial Smart Campaign (que incluye la transparencia, pero no se centra en esa cuestión)⁵⁷. Si bien la autorregulación es una forma de mostrar el compromiso con una financiación responsable y constituye un paso importante para que la transparencia de los precios funcione de manera eficaz, no incluye ningún mecanismo jurídico de ejecución y se fundamenta más bien en las fuerzas del mercado para distinguir entre las distintas instituciones de microfinanciación. Además, la autorregulación es voluntaria, mientras que la transparencia funciona mejor cuando es uniforme, es decir, cuando los clientes pueden comparar un producto entre todos los prestamistas y recibir la misma información, idealmente en el mismo formato. La legislación sobre la divulgación de las verdaderas condiciones de crédito en los Estados Unidos, Filipinas y Camboya demuestra claramente esta idea: las leyes de esos países establecen regímenes de divulgación de los precios, esencialmente mediante el uso de tasas de interés anuales o tasas de interés efectivo o la exigencia de que los precios se calculen mediante el método del tipo de interés de amortización decreciente, que ofrecen protección a los prestatarios contra los precios abusivos.

40. En consecuencia, la fijación de los precios de manera transparente es un elemento esencial para la creación de condiciones propicias para las microempresas: aunque son importantes en todo contrato de préstamo, las cuestiones relacionadas con la transparencia interesan sobre todo a los prestatarios poco sofisticados que no pueden sufragar el costo de un asesor. Se puede sugerir que los elementos siguientes son esenciales para crear transparencia en un entorno jurídico propicio: a) fórmulas estándar de fijación de precios (con estándares adecuados de divulgación); b) planes estándar de pago; c) aplicación de sanciones para asegurar que se cumplan los requisitos de revelación; y d) educación de los clientes y las instituciones microfinancieras sobre los requisitos de divulgación y los mecanismos de comunicación pertinentes.

41. Como se ha mencionado precedentemente, los informes sobre antecedentes de crédito y los derechos de prestamistas y prestatarios en las operaciones garantizadas son algunas de las medidas que más facilitan el acceso al crédito y la eficacia en la concesión de créditos; esas medidas funcionan mejor cuando se aplican conjuntamente. Al compartirse información mediante sistemas u oficinas de verificación de antecedentes de crédito (que no son el único instrumento para evaluar los riesgos)⁵⁸, se ayuda a los prestamistas a evaluar la solvencia de los clientes, se reducen los plazos de tramitación de los préstamos y se da lugar a tasas de incumplimiento menores, con lo que se facilita el acceso al crédito, en particular

⁵⁷ La Smart Campaign es una campaña a nivel mundial encaminada a promover la protección del cliente en la industria de la microfinanciación. La campaña se basa en una serie de principios que ayudan a las instituciones microfinancieras a prestar los servicios financieros respetando los derechos de los clientes. Véase www.smartcampaign.org.

⁵⁸ Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional, *Doing Business 2013, Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises*, pág. 72.

a las empresas pequeñas. Por ejemplo, en un estudio se observó que en los países en donde existen oficinas de verificación de antecedentes de crédito solo el 27% de las pequeñas y medianas empresas informó de problemas importantes para obtener financiación, en comparación con el 49% en los países en donde no existen esas oficinas. Igualmente, el 40% de las pequeñas y medianas empresas pudieron obtener préstamos bancarios en los países que cuentan con oficinas de este tipo, a diferencia del 28% en los países que carecen de ellas. Como se señaló en el coloquio de la CNUDMI sobre microfinanzas celebrado en de 2011, es necesario contar con legislación adecuada para respaldar el desarrollo y la regulación adecuada de las oficinas de verificación de antecedentes de crédito, que cumplen una función importante al facilitar información financiera correcta a los prestamistas con miras a evitar que otorguen préstamos imprudentes, limitando así sus pérdidas y contribuyendo a abaratar los créditos ofrecidos a todos sus clientes⁵⁹.

42. En el informe “Algunas cuestiones de orden legislativo que repercuten en la microfinanza”, preparado por la Secretaría en 2012, se señala que si bien la microfinanza no entraña necesariamente préstamos garantizados, cuando así ocurre “los prestatarios más frágiles ... pueden dar en prenda enseres domésticos esenciales para obtener préstamos con fines de microcomercio o de consumo”⁶⁰. Aunque algunas instituciones microfinancieras, por ejemplo Fundoz Mikro en Polonia y Grameen Bank en Bangladesh, no exigen garantías, está en aumento la tendencia de utilizar garantías como producto complementario de los métodos no garantizados tradicionales, como los préstamos grupales. Como generalmente es difícil evaluar las garantías en los micropréstamos, debido al tipo de activos utilizados, las garantías excesivas son casi una práctica normal en ese mercado, mucho más difundida que en los préstamos garantizados a las empresas más grandes. La frecuencia del exceso en las garantías también depende del marco jurídico del país y de la eficacia y rapidez de los tribunales al ejecutar el pago de las deudas. Los datos indican que los microprestamistas toman las garantías simplemente porque el sistema jurídico les permite hacerlo a un costo razonable. Ello corrobora la opinión de que es difícil definir los micropréstamos garantizados como verdaderos préstamos basados en activos, ya que faltan algunas de las características de ese tipo de préstamos, como la determinación de los adelantos sobre la base del valor de las garantías.

43. Sin embargo, al igual que ocurre con los préstamos garantizados a las empresas que superan la categoría de microempresas, el modelo de micropréstamos garantizados debería basarse en la capacidad del prestatario de generar ingresos (y, por ende, de pagar la deuda) más que en la garantía, que es algo secundario a lo que ha de recurrirse únicamente en caso de impago. Por ello, un régimen jurídico propicio para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, si bien se guiaría por el régimen de operaciones garantizadas establecido en la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas, podría considerar la posibilidad de hacer ciertos ajustes a fin de tener en cuenta las necesidades particulares de los microprestatarios (por ejemplo, límites a la ejecución, o exención de ejecución para ciertos activos, y otros mecanismos de ejecución, como la solución de controversias por vías alternativas) y facilitar el registro y, en

⁵⁹ A/CN.9/727, párr. 32.

⁶⁰ A/CN.9/756, párr. 3.

consecuencia, la transparencia de los micropréstamos (por ejemplo mediante la reducción de las tarifas de registro o la exención del pago de dichas tarifas).

F. Marco jurídico de la insolvencia y los procesos de liquidación de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas

44. Los regímenes de la insolvencia son fundamentales para crear un clima propicio para las inversiones y ayudan a promover el comercio y el crecimiento económico⁶¹. Un factor importante es que hacen que los acreedores estén más dispuestos a ofrecer préstamos⁶², lo cual es particularmente pertinente para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Según la Mesa Redonda de África de 2012 de la Asociación Internacional de Profesionales en Reestructuración, Insolvencia y Quiebras (INSOL), todavía hay países en donde los bancos no conceden préstamos a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas debido al riesgo que corren de no recuperarlos y la falta de confianza en el sistema judicial⁶³. Como se menciona mas arriba (véase el párr. 11), las microempresas y las pequeñas y medianas empresas son particularmente vulnerables, ya que soportan una carga excesiva de riesgos, y la crisis financiera mundial ha exacerbado ese problema, al provocar una escasez de capital circulante para las pequeñas y medianas empresas, una disminución de la financiación mediante la emisión de acciones; mayores tasas de rechazo de las solicitudes de financiación, tipos de interés más altos, exigencias más onerosas de garantías y un aumento en las insolvencias⁶⁴. Sin embargo, los regímenes de insolvencia comercial suelen ser demasiado complejos y costosos para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, y los regímenes de insolvencia del consumidor de que podrían valerse las microempresas y las pequeñas y medianas empresas a veces no existen o no tienen suficientemente en cuenta la naturaleza mercantil de la deuda. Además, los mecanismos oficiosos (descritos en la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia como negociaciones voluntarias de reestructuración) utilizados ampliamente para resolver la insolvencia de las empresas en varios países desarrollados, así como los procedimientos agilizados (también descritos en la Guía Legislativa) quizás no estén ampliamente difundidos en otras partes. Ello es particularmente pertinente en los países en desarrollo, en donde a menudo la economía se basa en gran medida en el sector no estructurado: cuando los empresarios del sector no estructurado se encuentran en una situación de dificultad financiera, sin acceso a fondos para superarla, se vuelven insolventes. La inexistencia de regímenes y mecanismos jurídicos adecuados, o unos regímenes jurídicos obsoletos o ineficientes en materia de insolvencia, impiden la supervivencia de las pequeñas empresas o que estas puedan revivir, ya que no existen medios para encontrar una solución satisfactoria con los acreedores. Habida cuenta de sus características, las microempresas y pequeñas y medianas empresas necesitan contar con regímenes

⁶¹ Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional, Doing Business 2013, Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, pág. 72.

⁶² Uttamchandani, A. Menezes, The Freedom to Fail: Why Small Business Insolvency Regimes are critical for Emerging markets, Economist's Outlook, 2010, pág. 264.

⁶³ A. Idighe, O. Kalu, Best practice and tailored reforms in African insolvency: lessons from INSOL, diciembre de 2012, nota 6.

⁶⁴ M. Uttamchandani, A. Menezes, The Freedom to Fail: Why Small Business Insolvency Regimes are critical for Emerging Markets, Economist's Outlook, 2010, págs. 263 y 264.

alternativos de insolvencia que sean agilizados, simplificados y eficientes en relación con los costos y que puedan ayudar a los empresarios a salir del mercado y volver a ingresar en él.

45. Un régimen de la insolvencia para las microempresas y pequeñas y medianas empresas debe basarse tanto en los regímenes que regulan la insolvencia de las sociedades comerciales como en los que regulan la insolvencia de las personas físicas. Ambos tienen características que satisfacen las necesidades de las microempresas y pequeñas y medianas empresas: el régimen de las sociedades comerciales centra su atención en el aprovechamiento máximo de los activos y la conservación de la empresa; la insolvencia de las personas físicas se centra en liberar al afectado de su obligación y ofrecerle la posibilidad de un nuevo comienzo a fin de respaldar y promover la actividad empresarial. El régimen de la insolvencia de las microempresas y pequeñas y medianas empresas debe combinar estas características: sus objetivos deben ser, por un lado, maximizar los activos y conservar la empresa, y, por el otro, liberar a los empresarios del caso de su obligación y permitirles un nuevo comienzo. Hay que distinguir los efectos que la insolvencia tiene en la empresa de los que tiene en la persona que se encuentra detrás de la empresa. La continuidad es posible para una sociedad mercantil, pero es más difícil para una persona que opera sin la protección del régimen societario. Es necesario establecer un equilibrio entre los intereses de los distintos participantes, y se debería evitar aplicar un criterio punitivo. El régimen de la insolvencia de las microempresas y pequeñas y medianas empresas también se debe adaptar a la características sociales y económicas de cada jurisdicción y debe tener en cuenta la definición de pequeña y mediana empresa establecida en esa jurisdicción.

46. Se puede mencionar el ejemplo de la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA). La OHADA está modernizando su Ley Uniforme de Insolvencia. El proyecto presentado por la secretaría permanente a los Estados miembros de la organización (que lo están examinando y, en consecuencia, tal vez la versión final sea diferente) hace que el marco de la insolvencia, entre otras cosas, se adapte más a las necesidades de las microempresas y pequeñas y medianas empresas. El nuevo régimen establecería procedimientos simplificados para la reorganización y liquidación de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, tanto en la etapa previa a la insolvencia como cuando el deudor ya es insolvente. En términos generales, el régimen especial para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas establecería plazos más breves, menores requisitos probatorios, menos etapas procesales y menos apelaciones (o ninguna). Sin embargo, los tribunales tendrán discreción para negarse a aplicar el procedimiento simplificado y podrían decidir utilizar el marco “estándar”. También se están realizando reformas en algunos estados de la India⁶⁵. Esos estados han modificado la Ley provincial de la insolvencia de 1920, centrando la atención en la eliminación de las sanciones penales, reduciendo el estigma e introduciendo requisitos procesales menos engorrosos. El Banco de Reserva de la India ha promovido un plan de reestructuración de la deuda para las pequeñas y medianas empresas viables, que se establece y pone en práctica dentro de los 90 días de la fecha de recepción de la solicitud de reestructuración formulada por el prestatario. Además, la creación de tribunales especializados en recuperación de la deuda ha acelerado la resolución

⁶⁵ Entre esos estados se encuentran Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Goa y Utar Pradesh.

de las reclamaciones, con lo que la probabilidad de pago ha aumentado un 28% y los tipos de interés se han reducido entre uno y dos puntos porcentuales⁶⁶.

47. En Colombia, una ley reciente⁶⁷ ha establecido un sistema de insolvencia para las personas naturales que introduce procedimientos híbridos y simplificados, elimina la responsabilidad penal del deudor insolvente y promueve la rehabilitación: la rehabilitación también se aplica a los comerciantes. Sin embargo, aparte de la rehabilitación, los comerciantes siguen estando sujetos al régimen de la insolvencia de las sociedades, que no hace distinciones en cuanto al tamaño o tipo de las empresas y está esencialmente ideado para afrontar los problemas de las grandes empresas, lo que entraña altos costos directos, requisitos y procedimientos complejos y mecanismos sofisticados para la participación de los acreedores.

48. Sin embargo, un marco eficiente para regular la insolvencia de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas no se puede basar únicamente en enmiendas a la legislación. Al igual que todos los sistemas de insolvencia, también se deben crear o fortalecer los arreglos institucionales y administrativos que permiten el funcionamiento del sistema a fin de asegurar la eficacia y eficiencia de los mecanismos de resolución de casos de insolvencia que se elaboren. Por ejemplo, la solución de controversias es particularmente pertinente y no se debería limitar a la vía judicial: podrían establecerse sistemas de solución de controversias por otras vías, incluidas las del arbitraje y la mediación. Otros elementos que deben tenerse en cuenta son los representantes de la insolvencia, la estructura administrativa del régimen, unos regímenes robustos de información sobre la capacidad crediticia (por ejemplo, mediante oficinas de verificación de antecedentes de crédito) y la creación de capacidad para los principales participantes en los procedimientos de insolvencia (por ejemplo, los magistrados)⁶⁸.

III. Orientaciones para el futuro

49. Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, que a menudo se establecen de forma oficiosa sin considerar cuidadosamente ni aclarar su estructura comercial, siguen sufriendo en muchos aspectos los efectos nocivos de normas jurídicas que distan de ser óptimas. Esas empresas normalmente carecen de la organización y los recursos necesarios para ejercer influencia en la necesaria reforma legislativa. Por otra parte, el sector no estructurado perpetúa el incumplimiento de la ley, lo que hace que aumente el riesgo de pérdidas de ingresos fiscales, corrupción y la creación de condiciones poco propicias para las inversiones. El sector no estructurado no evolucionará naturalmente hasta convertirse en un sector estructurado que permita el crecimiento de las empresas, la obtención de créditos en condiciones normales, el aumento del empleo y la contribución a la base tributaria. Una regulación excesiva, con demasiadas leyes, muchas de ellas desfasadas, desalienta la transición de las empresas hacia el sector

⁶⁶ Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional, *Doing Business 2013*, Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, pág. 22.

⁶⁷ Ley 1564 de 2012, 12 de Julio de 2012; se puede consultar en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425>.

⁶⁸ Véase también M. Uttamchandani, A. Menezes, *The Freedom to Fail: Why Small Business Insolvency Regimes are Critical for Emerging Markets*, *Economist's Outlook*, 2010, págs. 267 y 268.

estructurado. Es necesario mejorar la estructura jurídica para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, partiendo de una visión política global y no únicamente de mecanismos aislados. No bastará simplemente con adaptar las normas del sistema tradicional a las microempresas y pequeñas y medianas empresas. La experiencia ha demostrado que la transposición de leyes de otras jurisdicciones más evolucionadas tampoco ayuda, ya que la legislación debe adaptarse a la cultura y las circunstancias de cada país. En consecuencia, será importante preparar principios de naturaleza global que se puedan adaptar a cada país según sus necesidades. La CNUDMI ha demostrado ser un foro adecuado para la elaboración de principios y legislación de carácter general aceptables para una amplia variedad de países con distintas tradiciones jurídicas. En consecuencia, la Comisión podría desempeñar una función rectora para ayudar a crear igualdad de condiciones mediante la promoción de las mejores prácticas y compartiendo conocimientos con los países que soliciten orientaciones en esa esfera.

50. Entre los participantes en el coloquio hubo amplio consenso en recomendar que se estableciera un grupo de trabajo que se encargara de examinar los aspectos jurídicos necesarios para la creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Se subrayó que la labor encaminada a crear ese tipo de condiciones sería conforme con el mandato principal de la Comisión de promover la coordinación y cooperación en la esfera del comercio internacional, incluido el comercio transfronterizo regional. Ello también coincide con las conclusiones a que se llegó en el coloquio de la CNUDMI de 2011 de que las microfinanzas se habían convertido en una forma de finanzas transfronterizas reconocida mundialmente, que seguía creciendo en todo el mundo, que las lagunas jurídicas, reglamentarias y comerciales seguían impidiendo que el sector funcionara con el debido rendimiento y que ello había creado la necesidad de establecer normas jurídicas internacionales⁶⁹. Señalando que el reconocimiento transfronterizo de estas nuevas y variadas cuestiones legislativas y estructuras emergentes era necesario para que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas pudieran operar en los mercados regionales a fin de aportar un fundamento internacional reconocible para las operaciones y evitar los problemas que podrían surgir a resultas de la falta de reconocimiento comercial⁷⁰, los participantes también sugirieron que un instrumento flexible, como una guía legislativa o una ley modelo, según el tema, podría contribuir a armonizar las actividades en esa esfera e impulsar las reformas que impulsarían todavía más la participación de las microempresas en la economía. Al mismo tiempo, se señaló que se podría considerar la posibilidad de examinar algunos de los temas tratados en el coloquio en el contexto de los grupos de trabajo existentes, a fin de aprovechar al máximo los recursos de la Secretaría.

51. Independientemente de que se encarguen a un único grupo o a distintos grupos de trabajo, las orientaciones que prepare la Comisión deberán elaborarse de manera

⁶⁹ A/CN.9/727, párrs. 6 y 7.

⁷⁰ En ese sentido, el derecho contractual es muy distinto de otros ámbitos del derecho, como el derecho societario, en virtud de los cuales las empresas están obligadas según las formas de entidad jurídica creadas por el legislador, y la diversidad de entidades jurídicas existentes en los distintos países causa verdaderos problemas a las pequeñas y medianas empresas. Véase Cámara de Comercio Internacional, ICC Position on the European Commission proposal for a regulation on a Common European Sales Law, julio de 2012, pág. 2.

estrechamente coordinada, a fin de que el resultado sea un marco coherente y homogéneo que tenga en cuenta el ciclo comercial de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. El punto de partida podrían ser orientaciones que establezcan procedimientos simplificados de puesta en marcha y funcionamiento. En tal sentido, se debe prestar atención a unas estructuras societarias simplificadas que sean fáciles de establecer y exijan formalidades mínimas, responsabilidad limitada, gestión flexible y estructura de capitalización, a lo que debe añadirse una amplia libertad para contratar. Teniendo en cuenta que actualmente no existe ninguna norma ni directiva reconocida internacionalmente para los países que desean adoptar nuevas modalidades eficaces, dicho marco jurídico constituiría una contribución importante a la formalización de miles de empresas que, de lo contrario, permanecerían en el ámbito no estructurado⁷¹.

52. La Comisión quizá desee centrar su atención en los problemas que encuentran las microempresas y las pequeñas y medianas empresas para acceder a mecanismos de reparación jurídica, en particular los basados en tribunales judiciales. Tal vez la Comisión desee considerar si sería conveniente preparar notas⁷² sobre la manera en que se debería organizar un sistema de solución de controversias en el ámbito de la microfinanciación. Esas notas podrían ser utilizadas por legisladores y administradores al examinar si un país ha establecido un sistema que atiende con eficacia a las necesidades de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Además, habida cuenta del aumento exponencial del uso de Internet en todo el mundo (y de la capacidad conexas de solucionar controversias en línea), se podría estudiar la viabilidad de utilizar métodos informáticos para la solución de controversias relacionadas con la microfinanciación. Esos sistemas pueden estar al alcance de las poblaciones de bajos ingresos que residen en zonas rurales: en África, en los últimos diez años el uso de Internet aumentó aproximadamente el 3.000%, en el Oriente Medio aproximadamente el 2.250%, en América Latina más del 1.200% (por ejemplo, el Brasil ocupa el quinto lugar en el mundo, México el 12º y Colombia el 18º en cuanto al número de personas conectadas a Internet), y en Asia aproximadamente el 800%. En todo el mundo, el uso de Internet ha aumentado el 528% en el último decenio: aproximadamente la tercera parte de la población mundial está actualmente conectada a Internet. Se espera que ese número aumente al 47% para 2016⁷³. En consecuencia, quizá la Comisión desee examinar si los estándares jurídicos que estudia actualmente su Grupo de Trabajo III, relativos a las controversias en el comercio electrónico transfronterizo de menor cuantía, se podrían adaptar al contexto de la microfinanciación.

53. Las transferencias electrónicas (incluidos los pagos mediante dispositivos móviles) ofrecen a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas que operan en el sector no estructurado la oportunidad de tener un acceso efectivo a los servicios financieros. Los instrumentos existentes de la CNUDMI sobre comercio electrónico y transferencias de crédito internacionales pueden dar cabida a los

⁷¹ F. Reyes, *Latin American Company Law - A New Policy Agenda: Reshaping the Closely-Held Entity Landscape*, 2013, pág. ii.

⁷² Por ejemplo, en el pasado la Comisión ha preparado notas para asistir a los especialistas durante la tramitación del procedimiento de arbitraje; véanse las Notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral (1996).

⁷³ Internet World Stats: Usage and Population Statistics; se puede consultar en <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>.

sistemas de pago móviles, como se reconoció en el coloquio (véase el párrafo 35). No obstante, a fin de ampliar el alcance de esos instrumentos jurídicos, se sugirió que la Comisión vigilara la evolución del mercado, teniendo cuidado de evitar duplicaciones con otros órganos que establecen normas en esa esfera. La Comisión podría preparar un documento en que se resuman las recomendaciones de los organismos pertinentes que sirva de guía de referencia para los países que preparen leyes en esa esfera, y podría también recopilar las mejores prácticas que cabría destacar de las experiencias exitosas de los países que hayan creado condiciones jurídicas propicias para las operaciones y los servicios financieros móviles y deseen compartir lateralmente con otros países sus experiencias. Sería especialmente importante establecer definiciones claras de conceptos fundamentales como depósito, pago y dinero electrónico, así como ofrecer orientación sobre la distribución de los riesgos entre proveedores y clientes.

54. Unas condiciones jurídicas propicias que promuevan el acceso al crédito para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas permitirían tratar las cuestiones de derecho mercantil que surgieran en el contexto de los acuerdos sobre créditos garantizados y no garantizados. Las orientaciones aportadas por la Comisión, sobre la base de las mejores prácticas, podrían referirse a la transparencia en los préstamos y la ejecución de todo tipo de operaciones de préstamo. Las ventajas de aplicar a las microempresas y pequeñas y medianas empresas las recomendaciones de la Guía Legislativa de CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas debería ser el fundamento del debate. Otras cuestiones sobre las que podría ofrecerse orientación serían: i) el uso de garantías reales con y sin desplazamiento; ii) los activos respecto de los cuales no se pueden establecer garantías reales o estas no son ejecutables (por ejemplo, prestaciones laborales y enseres domésticos); iii) la exención de las operaciones microfinancieras garantizadas de tarifas de inscripción registral o búsqueda; iv) la financiación de adquisiciones (por ejemplo, el arrendamiento financiero); v) las prácticas injustas de cobro y ejecución; vi) la valuación de los activos y las garantías excesivas; vii) la importancia de las garantías en grupo; y viii) la importancia de las oficinas de verificación de antecedentes de crédito.

55. Por último, la Comisión quizá desee examinar la cuestión de la insolvencia de las microempresas y pequeñas y medianas empresas con el objetivo de asegurar que existan procedimientos acelerados y opciones de rescate comercial, a fin de elaborar alternativas adecuadas y viables a los procesos formales de insolvencia, que se ajusten tanto a las características fundamentales de un sistema eficaz de insolvencia como a las necesidades de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas⁷⁴. Las orientaciones que imparta podrían referirse, entre otras cosas, a cuestiones como el uso de procedimientos informales; la puesta en marcha de los procedimientos, incluidos los procedimientos agilizados; las soluciones aplicables, por ejemplo, la reorganización o liquidación; el tratamiento de los activos; y la estructura administrativa del régimen de la insolvencia. Las directrices elaboradas por organizaciones internacionales, como la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia (2004) o la Declaración de principios de la INSOL para un criterio global aplicable a la renegociación con múltiples acreedores, podrían servir de fundamento para esa labor.

⁷⁴ A. Indigbe, O. Kaln, Best practice and tailored reforms in African insolvency: lessons from INSOL, diciembre de 2012, pág. 2.

D. Solución de controversias comerciales: posible labor futura en materia de solución de controversias comerciales

(A/CN.9/785)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-5
II. Temas señalados por la Comisión para la labor futura	6-15
1. Revisión de las Notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral	7-10
2. Arbitrabilidad	11-15
III. Cuestiones planteadas como temas para la posible labor futura	16-21
1. Procedimientos múltiples y paralelos en los arbitrajes relacionados con inversiones	17-18
2. Juntas de arbitraje sobre controversias	19-20
3. Otros temas	21

I. Introducción

1. Con objeto de facilitar las deliberaciones de la Comisión sobre los temas que el Grupo de Trabajo ha de examinar con carácter prioritario una vez concluida su labor actual sobre la preparación de una norma jurídica relativa a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, la presente nota contiene una breve reseña de la revisión de las Notas de la CNUDMI sobre organización del proceso arbitral (1996)¹ y sobre la cuestión de la arbitrabilidad. También contiene una lista de temas en relación con los cuales los profesionales del ámbito del arbitraje, por ejemplo en ocasión de una mesa redonda organizada conjuntamente por la Secretaría y el Instituto de Arbitraje Internacional (París), en abril de 2012, han señalado que la falta de soluciones o de soluciones armonizadas crean dificultades en la práctica y tal vez justifique proseguir con las deliberaciones.

2. A título de antecedentes, cabe recordar que el Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) reanudó su labor en 2000, en cumplimiento del mandato que le había confiado la Comisión en su 32º período de sesiones en 1999². Aprovechando la oportunidad de examinar la conveniencia y la viabilidad de seguir desarrollando el régimen legal del arbitraje comercial internacional, la Comisión estimó que había llegado el momento de evaluar la experiencia amplia y positiva adquirida con la promulgación de normas de derecho interno inspiradas en la Ley Modelo de

¹ Anuario de la CNUDMI, vol. XXVII, 1996, tercera parte, anexo II.

² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/54/17), párr. 337.*

la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985)³ (“Ley Modelo sobre Arbitraje”), así como la aplicación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (1976)⁴ y del Reglamento de Conciliación de la CNUDMI (1980)⁵, y de determinar, en un foro universal como la Comisión, si eran aceptables las ideas y las propuestas presentadas para mejorar las leyes, reglamentos y prácticas aplicables al arbitraje⁶.

3. La Comisión examinó varios temas para la posible labor futura en ese ámbito, sobre la base de una nota que tuvo ante sí en ese período de sesiones, titulada “Posible labor futura en materia de arbitraje comercial internacional” (A/CN.9/460)⁷. La extensa lista de posibles temas que figuraba en esa nota incluía cuestiones que son objeto de proyectos actuales de la CNUDMI, como la solución de controversias en línea o la orientación relativa a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (1958)⁸ (“Convención de Nueva York”), así como temas que han sido objeto de la labor normativa realizada por el Grupo de Trabajo.

4. En relación con esto último, desde que el Grupo de Trabajo reanudó su labor en 2000, la Comisión ha aprobado los siguientes textos en materia de solución de controversias: en su 35º período de sesiones, en 2002, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional, con la Guía para su incorporación al derecho interno y su aplicación⁹; en su 39º período de sesiones, en 2006, disposiciones normativas por las que se modificaba la Ley Modelo sobre el Arbitraje, relativas a la forma del acuerdo de arbitraje y a las medidas cautelares, así como una recomendación relativa a la interpretación del párrafo 2) del artículo II y del párrafo 1) del artículo VII de la Convención de Nueva York¹⁰; y en su 43º período de sesiones, en 2010, el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010)¹¹.

5. En su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión encomendó al Grupo de Trabajo la tarea de preparar una norma jurídica modelo sobre el tema de la transparencia en los procedimientos de arbitraje entre inversionistas y Estados

³ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/40/17)*, anexo I; Anuario de la CNUDMI, vol. XVI: 1985, tercera parte, anexo I.

⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/31/17)*, párr. 57; Anuario de la CNUDMI, vol. VII: 1976, primera parte, capítulo II, sección A, párr. 57.

⁵ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/35/17)*, capítulo V, sección A, párr. 106; Anuario de la CNUDMI, vol. XI: 1980, tercera parte, anexo II.

⁶ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/54/17)*, párr. 337.

⁷ *Ibid.*, párrs. 333 a 380.

⁸ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 330, núm. 4739, pág. 3; Acta final y Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional, Nueva York, 20 de mayo a 10 de junio de 1958 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta 58.V.6).

⁹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/57/17)*, anexo I (únicamente la Ley Modelo); Anuario de la CNUDMI, vol. XXXIII: 2002, tercera parte, anexos I y II.

¹⁰ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/61/17)*, párrs. 87 a 181 y anexos I y II del informe.

¹¹ *Ibid.*, sexagésimo quinto período de sesiones, *Suplemento núm. 17 (A/65/17)*, párr. 187 y anexo I del informe.

entablados en el marco de un tratado. En su actual período de sesiones, la Comisión tendrá ante sí, para su examen y posible aprobación, el resultado de la labor del Grupo de Trabajo sobre ese tema, a saber, el proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (véase el documento A/CN.9/783). La Comisión también tendrá ante sí proyectos de instrumentos sobre la aplicabilidad de ese reglamento a la solución de controversias que surjan en el marco de tratados de inversiones existentes (véase el documento A/CN.9/784).

II. Temas señalados por la Comisión para la labor futura

6. Entre los temas que ha señalado la Comisión para la labor futura figuran la revisión de las Notas de la CNUDMI sobre organización del proceso arbitral (1996) y la cuestión de la arbitrabilidad.

1. Revisión de las Notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral

7. La Comisión, después de proceder a una deliberación inicial en su 26° período de sesiones, en 1993¹², finalizó las Notas de la CNUDMI sobre organización del proceso arbitral (a las que también se hace referencia más adelante como “Notas”) en su 29° período de sesiones, en 1996¹³. En ese período de sesiones, la Comisión aprobó los principios que habían inspirado la redacción de las Notas, entre los cuales figuraba el de que estas no deberían afectar en modo alguno a la flexibilidad del proceso arbitral; que era necesario evitar el establecimiento de requisitos más allá de las leyes, reglamentos o prácticas existentes y, en particular, asegurarse de que el solo hecho de que las Notas o cualquier parte de ellas no fueran aplicadas no llevaría a la conclusión de que se había violado algún principio procesal ni sería motivo para negarse a hacer cumplir un laudo; y que las Notas no deberían tratar de armonizar prácticas arbitrales dispares ni recomendar la utilización de un procedimiento en particular¹⁴.

8. En su 36° período de sesiones, en 2003, se formularon propuestas ante la Comisión para que se considerara la posibilidad de incluir la revisión de las Notas en la labor futura¹⁵. En su 45° período de sesiones, en 2012, la Comisión recordó el acuerdo al que había llegado en su 44° período de sesiones¹⁶, en 2011, en el sentido de que las Notas requerían una actualización a raíz de que se hubiera aprobado la versión revisada de 2010 de su Reglamento de Arbitraje¹⁷. En su 45° período de

¹² *Ibid.*, cuadragésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/48/17), párrs. 291 a 296. Sobre el examen, en el período de sesiones de la Comisión en 1994, de un proyecto titulado “Proyecto de Directrices para las Reuniones Preparatorias en el Procedimiento Arbitral”, véase *Ibid.*, cuadragésimo noveno período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/49/17), párrs. 111 a 195; sobre el examen, en el período de sesiones de la Comisión celebrado en 1995, de un proyecto titulado “Proyecto de Notas sobre organización del proceso arbitral”, véase *Ibid.*, quincuagésimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/50/17), párrs. 314 a 373.

¹³ *Ibid.*, quincuagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/51/17), párrs. 11 a 54.

¹⁴ *Ibid.* párr. 13.

¹⁵ *Ibid.*, quincuagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/58/17), párr. 204.

¹⁶ *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párrs. 205 y 207.

¹⁷ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 70.

sesiones, la Comisión confirmó que la siguiente misión de la Secretaría sobre el tema de la solución de controversias sería la revisión de las Notas y que decidiría en un futuro período de sesiones si el proyecto de revisión de las Notas debería ser examinado por el Grupo de Trabajo antes de presentarse a la Comisión¹⁸.

9. Los días 21 y 22 de marzo de 2013, la CNUDMI, en cooperación con el Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara Económica Federal de Austria, celebró en Viena una conferencia en la que se examinaron, entre otras cosas, las Notas de la CNUDMI sobre organización del procedimiento arbitral y las cuestiones que podrían tenerse en cuenta para su revisión¹⁹. Además, se puso a disposición de los profesionales interesados un cuestionario sobre si se deberían revisar las Notas y cómo, a través de diversos canales de difusión, en particular el sitio web de la CNUDMI. Para facilitar las deliberaciones de la Comisión sobre la cuestión de la revisión de las Notas, a continuación figura una reseña breve y no exhaustiva de las sugerencias formuladas por los profesionales en ocasión de la conferencia conjunta, así como en respuesta al cuestionario:

a) Comentario general sobre las Notas. Se confirmó que las Notas se utilizaban con mucha frecuencia y constituían un instrumento útil para ayudar a los árbitros y las partes en la organización del procedimiento arbitral. También se destacó que las Notas eran diferentes de muchas otras directrices porque ayudaban a los árbitros enumerando y describiendo brevemente las cuestiones sobre las cuales podía ser conveniente adoptar decisiones relativas a la organización del procedimiento arbitral, sin promover ningún enfoque ni práctica en particular;

b) Lugar del arbitraje (véase la sección 3 de las Notas). Se sugirió que las Notas deberían proporcionar más información a los usuarios sobre las consecuencias jurídicas de la elección del lugar del arbitraje, diferenciando el lugar físico del arbitraje (determinado por factores concretos como la conveniencia, la proximidad de las pruebas, etc.) de la sede del arbitraje (determinada por factores jurídicos);

c) Costas (véase la sección 5 de las Notas). Se propuso que en un proyecto revisado de las Notas se abordaran las cuestiones relativas a las costas y el control de las costas. Las actuales Notas solo abordan la cuestión de los depósitos en relación con las costas;

d) Utilización de medios electrónicos (véase, por ejemplo, la sección 8 de las Notas). Es necesario actualizar la terminología de las Notas relativa a las comunicaciones. Además, las Notas podrían contener sugerencias que indicaran la adecuación y la eficacia en función del costo de los medios electrónicos de comunicación y la presentación de documentos por vía electrónica, así como los obstáculos que dificultan la comunicación por vía electrónica y las ventajas de esta forma de comunicación. También se formularon propuestas más innovadoras, incluida la creación de una página “wiki” en línea para las Notas, a fin de que los profesionales pudieran formular comentarios relativos a cada uno de sus párrafos y se creara de esa forma un documento vivo;

¹⁸ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 70.

¹⁹ Para consultar las ponencias presentadas en la ocasión de la conferencia conjunta anual CNUDMI-VIAC-YAAP véase www.viac.eu/en/news-events/news-en/9-nicht-kategorisiert/127-presentations-viac-seminar (disponible el 12 de abril de 2013).

e) Elaboración y divulgación de documentos (véanse las secciones 10 y 13 de las Notas). Se sugirió que en las Notas se podrían aclarar mejor las cuestiones que habían de examinar las partes y el tribunal en relación con las normas que habrían de aplicarse a la presentación de documentos y con la divulgación y elaboración electrónica de documentos;

f) Peritos (véase la sección 16 de las Notas). Se propuso completar las Notas con posibilidades más recientes de colaboración entre peritos, como el trabajo en equipo o mediante conferencias de peritos. Se solicitó orientación sobre las ventajas e inconvenientes de que los peritos fueran designados por las partes o por el tribunal;

g) Procedimiento multilateral (véase la sección 18 de las Notas). Se señaló que sería útil disponer de información sobre cómo abordar cuestiones específicas del arbitraje multilateral que pudieran plantearse en diversas etapas del procedimiento y que en las Notas debería tratarse esa cuestión más en detalle. Se sugirió que una actualización a ese respecto podría incluir notas sobre la cuestión de las acciones colectivas;

h) La negativa de un demandado de participar en el procedimiento y las tácticas dilatorias. Se sugirió que las Notas podrían presentar posibles soluciones a las partes y los tribunales en caso de que un demandado se negara a participar en el procedimiento o se valiera de tácticas dilatorias. En particular, se indicó que las Notas deberían dar más información sobre la forma de garantizar la eficacia del procedimiento en esas situaciones y sobre las medidas que se pudieran adoptar para asegurar la ejecución de los laudos;

i) Efecto del arbitraje en terceros. El procedimiento arbitral puede afectar a terceros, en particular, por ejemplo, cuando se dictan medidas cautelares, y se propuso que las Notas proporcionaran información en ese contexto;

j) Arbitraje en el marco de tratados de inversión. Se sugirió que sería conveniente proporcionar algunas orientaciones especiales sobre las prácticas vigentes en el ámbito de los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, en relación con algunas esferas a las que se hacía referencia en las Notas.

10. Si la Comisión decidiera que el Grupo de Trabajo debe considerar la revisión de las Notas como cuestión prioritaria, la Secretaría presentaría al Grupo de Trabajo una lista anotada más detallada de las posibles esferas de revisión.

2. Arbitrabilidad

11. Desde su 36º período de sesiones, en 2003, la Comisión ha señalado en varias ocasiones que el tema de la arbitrabilidad era una cuestión importante que merecía considerarse un tema prioritario para la labor futura²⁰.

²⁰ *Ibid.*, quincuagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/58/17), párr. 204; quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/59/17), párr. 60; sexagésimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/60/17), párr. 178; sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/61/17), párr. 187; sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17, primera parte), párr. 177; sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/63/17), párr. 316; sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 203.

12. La Comisión ha seleccionado varias cuestiones relacionadas con la arbitrabilidad, como las relativas a las controversias internas de las empresas, los bienes inmuebles, la insolvencia o la competencia desleal, para su posible examen²¹. Se dijo también que correspondía al Grupo de Trabajo determinar si sería posible definir en términos genéricos los asuntos que fueran dirimibles por arbitraje, por ejemplo mediante una lista ilustrativa, o si era preferible preparar una disposición legislativa respecto a la arbitrabilidad, que se limitara a señalar los temas que no se consideraban dirimibles por arbitraje.

13. En el contexto de las deliberaciones anteriores de la Comisión en esta esfera, también se expresó la advertencia de que el tema de la arbitrabilidad planteaba cuestiones de orden público que según se sabía era muy difícil de definir de manera uniforme, y que si se preparaba de antemano una lista predefinida de las cuestiones susceptibles de arbitraje se podía restringir innecesariamente la capacidad de los Estados para atender a ciertas preocupaciones de orden público que probablemente evolucionarían con el tiempo²². En la medida en que se debía considerar esta cuestión, el objetivo no debía ser conseguir la uniformidad de las soluciones sino procurar que las distintas opiniones sobre ese tema fueran transparentes²³. La Comisión, en su 44º período de sesiones, en 2011, afirmó que el Grupo de Trabajo debería mantener en su programa el tema de si una controversia era o no susceptible de arbitraje²⁴.

14. La Comisión tal vez desee tomar nota de que la forma y el contenido de toda labor futura sobre la arbitrabilidad debería definirse con mayor precisión. A ese respecto, la Comisión tal vez desee considerar si ese tema se podría abordar debidamente en el marco del proyecto de guía sobre la Convención de Nueva York que prepara actualmente la Secretaría; por ejemplo, en la sección relativa al artículo V 2) a) de la Convención se podría proporcionar orientación sobre la arbitrabilidad e información sobre cómo encarar la admisibilidad o no del arbitraje de determinadas cuestiones en diversos ordenamientos. En su actual período de sesiones, la Comisión tendrá ante sí partes del texto de la guía (véase el documento A/CN.9/786).

15. Si la Comisión considera que el resultado de toda labor futura sobre la arbitrabilidad debe consistir en un texto legislativo por el que se enmienda la Ley Modelo sobre Arbitraje, quizás desee decidir si corresponde proceder a su examen en una etapa ulterior, como parte de una posible revisión general de la Ley Modelo sobre Arbitraje, que actualmente no dice nada al respecto.

²¹ *Ibid.*, quincuagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/58/17), párr. 204; quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/59/17), párr. 60; sexagésimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/60/17), párr. 178; (véanse también los informes del Grupo de Trabajo sobre la labor realizada en sus períodos de sesiones 42º y 44º (A/CN.9/573, párr. 100 y A/CN.9/592, párr. 90)).

²² *Ibid.*, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/61/17), párr. 185.

²³ *Ibid.*, quincuagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/54/17), párr. 352.

²⁴ *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/66/17), párr. 203.

III. Cuestiones planteadas como temas para la posible labor futura

16. La Comisión tal vez desee tomar nota de los siguientes temas en relación con los cuales los profesionales del ámbito del arbitraje han señalado que la falta de soluciones o de soluciones armonizadas crean dificultades en la práctica y tal vez se justifique seguir deliberando sobre ellos en el marco de la posible labor futura.

1. Procedimientos múltiples y paralelos en los arbitrajes relacionados con inversiones

17. Se ha sugerido que la cuestión de los procedimientos paralelos es cada vez más importante, sobre todo en el ámbito del arbitraje relacionado con las inversiones, y que valdría la pena que la CNUDMI siguiera examinándola. En particular, se ha indicado que suele suceder que un arbitraje se inicie en relación con una determinada controversia y que, al mismo tiempo, las partes relacionadas inicien procedimientos paralelos, solicitando, total o parcialmente, la misma reparación. En algunos procedimientos de arbitraje relacionados con inversiones se observa a menudo la participación de una empresa matriz que invoca disposiciones de un tratado contra un determinado Estado, mientras que su filial, con un domicilio legal diferente, invoca disposiciones de otro tratado contra el mismo Estado, basándose en los mismos hechos. En otros casos, los especialistas han observado que se plantea una dificultad cuando una empresa extranjera inicia un arbitraje basado en el tratado de inversión que corresponde a su domicilio legal mientras que una filial local inicia otra acción sobre la base de los mismos hechos en el marco del mismo contrato y del mismo tratado de inversión.

18. Tratar la cuestión de los procedimientos paralelos también se ajustaría a la intención de promover un enfoque del arbitraje armonizado y coherente. Para seguir examinando las propuestas concretas a fin de evitar un resarcimiento múltiple en relación con los mismos hechos en el contexto del arbitraje internacional, la Comisión tal vez desee tomar nota de que en noviembre de 2013 la Secretaría organizará, conjuntamente con otras organizaciones interesadas, una conferencia sobre este tema y la informará de las cuestiones que se planteen en esa ocasión.

2. Juntas de arbitraje sobre controversias

19. Las juntas de arbitraje sobre controversias cobraron importancia internacional por primera vez en 1995, cuando el Banco Mundial introdujo el concepto en su régimen de contratación pública. Estas juntas tienen por objeto ocuparse inmediatamente de los asuntos a medida que se plantean entre las partes en un contrato y después formular recomendaciones para su solución. No es necesario que las recomendaciones tengan un valor contractual a menos que las partes decidan lo contrario. Si las partes en el contrato no desean aceptar la recomendación de la junta o someterse a una decisión vinculante, el asunto pasa a ser objeto de un procedimiento formal mediante arbitraje o en el marco de un litigio. Originalmente las juntas de controversias se limitaban al ámbito de los contratos de construcción. Hoy en día intervienen en muy diversos sectores de actividad, como las

contrataciones de organismos espaciales, la construcción naval y los contratos de tecnología de la información²⁵.

20. Se sugirió que sería muy provechoso disponer de un texto armonizado relativo a esa cuestión, que pudiera promoverse y aplicarse con frecuencia por las partes en los contratos, puesto que se ha demostrado la utilidad de este mecanismo para la solución de controversias.

3. Otros temas

21. Entre otros temas que se consideró importante examinar figuraban los siguientes:

a) Orientación sobre el papel del Estado de origen del inversor en un arbitraje sobre inversiones. Se sugirió que sería útil disponer de orientaciones con respecto al Estado de origen del inversor en un arbitraje sobre inversiones. Se propuso que se elaboraran directrices sobre buenas prácticas para el Estado de origen en un arbitraje sobre inversiones, en particular en la medida en que el Estado tuviera acceso a los *travaux préparatoires* de los instrumentos internacionales;

b) Arbitraje en causas colectivas. Dada la gran variedad de causas colectivas que son objeto de arbitraje internacional, se ha sugerido que el tema podría examinarse con miras a una labor de armonización;

c) Ejecución de los acuerdos conciliatorios. Para apoyar la realización de una labor futura sobre las cuestiones relativas a la ejecución de los acuerdos conciliatorios dimanantes de la conciliación y la mediación, la Comisión tal vez desee tomar nota de que el Congreso de la CNUDMI celebrado en 2007 examinó ese tema, como también lo hizo el Grupo de Trabajo en la preparación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional;

d) Facultad para concertar acuerdos de arbitraje. Se consideró que la cuestión de determinar la legislación aplicable a la autoridad de una persona para obligar a una parte en un acuerdo de arbitraje, así como la forma y el contenido que debía tener esa autoridad, creaba dificultades en la práctica dado que las leyes nacionales no se pronunciaban al respecto;

e) Financiación de terceros. La financiación de terceros es una práctica que consiste en un arreglo concluido entre una entidad de financiación y una parte en el arbitraje con objeto de financiar los costos y costas de una de las partes, total o parcialmente. La Comisión tal vez desee considerar si deben examinarse más a fondo las cuestiones que plantea esa práctica.

²⁵ La Cámara de Comercio Internacional adoptó en 2004 un reglamento relativo a las juntas de arbitraje sobre controversias (véase www.iccwbo.org/). El Foro de Conciliación y Arbitraje Internacionales adoptó en 2008 el "Dispute Board Rules" (véase www.ficacic.com).

E. Fraude comercial**(A/CN.9/788)****[Original: inglés]****Índice**

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-5
II. Los Indicadores de fraude comercial	6-7
III. Posible labor futura sobre el fraude comercial	8-17
A. Coloquio	8-13
B. Un mecanismo para la labor futura.	14-17
IV. Recomendaciones para el examen por la Comisión	18

I. Introducción

1. La Comisión ha examinado la cuestión del fraude comercial internacional en varias ocasiones a partir de su 35º período de sesiones, celebrado en 2002¹, y los informes de la Secretaría a la Comisión en los que se expone la labor realizada a este respecto se pueden consultar en el sitio web de la CNUDMI². Además, la CNUDMI organizó un coloquio sobre fraude comercial en abril de 2004 en el que se trató el tema en el contexto de las siguientes esferas amplias: labor de otras organizaciones internacionales; fraude bancario y comercial; investigación; fraude cibernético; prevención; transporte; seguro; recuperación; blanqueo de dinero; insolvencia; enjuiciamiento; adquisiciones; papel de los profesionales; y valores (véase A/CN.9/555). Después del coloquio, la Comisión aprobó la preparación de un estudio destinado a prestar asistencia a los gobiernos y a la comunidad comercial internacional en la lucha contra el fraude comercial³.

2. Se celebraron dos reuniones de un grupo de expertos en fraude comercial en octubre de 2005 y enero de 2007, respectivamente. Esas sesiones contribuyeron a la

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/57/17), párrs. 279 a 290; Ibid., quincuagésimo octavo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/58/17), párrs. 231 a 241; Ibid., quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/59/17), párrs. 108 a 112; Ibid., sexagésimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/60/17), párrs. 216 a 220; Ibid., sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/61/17), párrs. 211 a 217; Ibid., sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17 (Part I)), párrs. 196 a 203; Ibid., sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/63/17), párrs. 339 a 347; Ibid., sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párrs. 345 a 355; e Ibid., sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 232.*

² Véanse A/CN.9/540, 2003; A/CN.9/555, 2004; A/CN.9/600, 2006; A/CN.9/624, Add.1 y 2, 2007; y A/CN.9/659, Add.1 y 2, 2008.

³ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/59/17), párrs. 108 a 112.*

preparación del estudio solicitado, que se titula “Indicadores de fraude comercial” (A/CN.9/624, Add.1 y Add.2) y sirve para determinar las características comunes en los planes fraudulentos típicos que advierten de su naturaleza, y para explicar esas características. A solicitud de la Comisión, los “Indicadores de fraude comercial” se distribuyeron a los Estados Miembros en 2007 para que formularan observaciones (A/CN.9/659, Add.1 y Add.2), y seguidamente la Comisión solicitó en 2008 a la Secretaría que efectuase los ajustes y adiciones que fueran convenientes para mejorar la documentación y la publicase como nota de información de la Secretaría con fines didácticos y de prevención del fraude. La Comisión también expresó su opinión de que la Secretaría podría incorporar la documentación como componente de su labor más amplia de asistencia técnica, que podría abarcar labores de difusión y explicación a los gobiernos y las organizaciones internacionales con la finalidad de potenciar las ventajas didácticas y preventivas de dicha documentación. Además, podría alentarse a su vez a los gobiernos y las organizaciones internacionales a que dieran publicidad a la documentación y la utilizaran de la manera que estimasen conveniente, por ejemplo, adaptándola para atender las necesidades de diversos grupos o sectores destinatarios⁴.

3. Asimismo, de conformidad con lo solicitado por la Comisión⁵, la Secretaría ha seguido participando en la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre delincuencia económica y usurpación de identidad. En particular, la secretaria de la CNUDMI ha participado en el grupo básico de expertos de la UNODC sobre el delito relacionado con la identidad, que se constituyó para reunir periódicamente a representantes de gobiernos, entidades del sector privado, organizaciones internacionales y regionales y círculos académicos a fin de poner en común experiencias, elaborar estrategias, facilitar nuevas investigaciones y convenir en medidas prácticas de lucha contra los delitos relacionados con la identidad. La reunión más reciente del grupo básico de expertos se celebró en enero de 2013, y de ella surgió un proyecto de resolución del Consejo Económico y Social (E/CN.15/2013/L.6/Rev.1) en el que se solicita a la UNODC que siga esforzándose, en consulta con la CNUDMI, “por promover el entendimiento mutuo y el intercambio de opiniones y conocimientos técnicos entre diversas partes interesadas, en particular entre entidades del sector público y del sector privado, sobre asuntos pertinentes a los delitos relacionados con la identidad, mediante la futura labor del grupo básico de expertos en delitos relacionados con la identidad, incluida la elaboración de un proyecto de legislación sobre dichos delitos”.

4. En su 45º período de sesiones, celebrado en 2012, se recordó a la Comisión que habían transcurrido más de diez años desde que examinara por primera vez la cuestión del fraude comercial. Se sostuvo que “el fraude comercial seguía siendo un gran obstáculo para el comercio internacional y se señaló que, dada la función vital que desempeñaba el sector privado en la lucha contra el fraude comercial, la CNUDMI se encontraba en una situación privilegiada para coordinar los esfuerzos que se llevaban a cabo al respecto y para avisar a los legisladores y a las autoridades normativas acerca de los importantes problemas que creaba esa

⁴ *Ibid.*, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/63/17), párrs. 342 y 343 y sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párr. 348.

⁵ *Ibid.*, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/63/17), párr. 347 y sexagésimo cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/64/17), párr. 354.

cuestión”⁶. Además, se propuso que, en la medida en que lo permitieran los recursos disponibles, la Secretaría organizara un coloquio sobre este tema⁷. A fin de estudiar la viabilidad y conveniencia de celebrar un coloquio de esa índole, la Secretaría organizó una reunión oficiosa de expertos en la materia que se celebró en Viena (Austria) los días 29 y 30 de abril de 2013.

5. En la reunión oficiosa de expertos se examinó la labor sobre fraude comercial realizada por la CNUDMI hasta la fecha y se consideró si la labor futura en esa esfera sería útil y, de serlo, el posible alcance de esa labor.

II. Los Indicadores de fraude comercial

6. En la reunión oficiosa de expertos se examinaron los Indicadores de fraude comercial y se formularon varias sugerencias para armonizar el texto con las últimas novedades en ese ámbito desde que se revisó por última vez el documento en 2010.

7. En la reunión oficiosa de expertos se convino en que se publicasen los Indicadores de fraude comercial de forma apropiada en cuanto fuera viable y se les diera la distribución más amplia posible. A este respecto, se sugirió que, en caso de que se celebrara un Coloquio, resultaría sumamente beneficioso para facilitar la distribución y la actualización de los Indicadores de fraude comercial.

III. Posible labor futura sobre el fraude comercial

A. Coloquio

8. En la reunión oficiosa de expertos se sugirió que existían algunas esferas importantes con respecto al fraude comercial que justificaban que se les prestase más atención en un foro más amplio. Se recordó que el coloquio de la CNUDMI celebrado en 2004 constituía un modelo útil para tratar cuestiones en un contexto que despertara el interés y atrajera la participación de un amplio espectro de especialistas dedicados a combatir el fraude comercial.

9. En particular, se observó que los adelantos de las comunicaciones electrónicas planteaban problemas concretos mediante el robo de la identidad de empresas y bancos, el hecho de que los receptores de mensajes no pudieran identificar a los remitentes con certeza y la proliferación de sitios web que imitaban a los de entidades legítimas, pero que estaban controlados por defraudadores. Se observó que las consecuencias de esas nuevas situaciones afectaban a todos los aspectos de la actividad empresarial, financiera y comercial, desde la venta de bienes, la información y los servicios hasta la solución de controversias en línea.

10. También se sugirió que estaba justificado examinar de nuevo las esferas estudiadas en el coloquio de 2004 habida cuenta de las novedades recientes, como la computación en nube, los sistemas móviles de pago, la expansión del acceso a Internet y la crisis financiera mundial, que habían exacerbado los efectos del fraude comercial. Se observó que la utilización de Internet había aumentado a un ritmo

⁶ *Ibid.*, sexagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/67/17), párr. 232.

⁷ *Ibid.*

espectacular en todo el mundo, registrándose un incremento del 528% en los últimos diez años. Se señaló asimismo que una tercera parte de la población del mundo ya estaba conectada a Internet, con aumentos en el último decenio del 3.000% en África, el 2.250% en el Oriente Medio, el 1.200% en América Latina y el 800% en Asia⁸.

11. Se recordó que la Comisión convino en 2004⁹ en que sería útil, siempre que procediera, que se examinaran ejemplos de fraude comercial en los contextos concretos de los proyectos llevados a cabo por la CNUDMI, de manera que los delegados que hubieran participado en esos proyectos pudieran tener en cuenta el problema del fraude en sus deliberaciones, y se solicitó a la Secretaría que facilitara esos exámenes cuando procediera. La reunión oficiosa de expertos expresó la opinión de que, aunque algunos de los textos de la CNUDMI trataban cuestiones de fraude, muchos no lo hacían y que incluso cuando se abordaba el fraude, la atención que se le prestaba se centraba en su efecto en las obligaciones existentes y no en su identificación y prevención. No obstante, se señaló que la gestión de la identidad y los pagos móviles figuraban en la lista de temas de la posible labor futura del Grupo de Trabajo IV¹⁰. También se sugirió que el tipo de conocimientos especializados necesarios para formular reglas normativas de derecho mercantil en esferas discretas no era necesariamente el mismo que se necesitaba para determinar posibilidades de fraude comercial y la forma de combatirlas; por tanto, se sugirió que tal vez fuera útil concentrarse por separado en las posibilidades y peligros de fraude comercial en las esferas a que se dedicaban los Grupos de Trabajo de la CNUDMI.

12. Reconociendo la singular utilidad de los Indicadores de fraude comercial, se sugirió que en un coloquio podría actualizarse el texto y considerarse las adiciones que pudieran resultar pertinentes, estudiar la forma de promoverlos y movilizar energías fuera de las Naciones Unidas para promoverlos y mantenerlos actualizados.

13. La reunión oficiosa de expertos opinó que, habida cuenta de la constante amenaza para el comercio internacional que constituía el fraude comercial, la necesidad de fomentar la coordinación y la educación y la posición privilegiada que ocupaba la CNUDMI para reunir a representantes de los gobiernos y otras organizaciones afectados por el fraude comercial, debería considerarse la organización de un coloquio internacional patrocinado por la CNUDMI.

B. Un mecanismo para la labor futura

14. La reunión oficiosa de expertos recordó que en el informe a la Comisión sobre el coloquio de 2004 se puso de relieve que la educación y la capacitación desempeñaban un papel importante en la prevención del fraude y podrían ayudar a hacer frente a los problemas derivados de la insuficiencia de la información sobre la

⁸ Internet World Stats: Usage and Population Statistics, www.internetworldstats.com (consultado por última vez el 6 de mayo de 2013).

⁹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/59/17)*, párr. 111.

¹⁰ *Ibid.*, sexagésimo sexto período de sesiones, *Suplemento núm. 17 (A/66/17)*, párrs. 236, 237 y 239. Véanse también dos notas de la Secretaría: “Labor actual y posible labor futura en materia de comercio electrónico” (A/CN.9/728) y “Panorama general de la gestión de la identidad digital” (A/CN.9/WG.IV/WP.120).

incidencia del fraude comercial¹¹. En el informe se señaló asimismo que la prevención correspondía principalmente al ámbito del derecho mercantil y de la autorreglamentación de la comunidad comercial, y que se manifestaba a través de normas como las relativas al buen gobierno empresarial, las normas de conducta profesional y las auditorías¹². La reunión sugirió que el valor de un proceso por el que pudieran actualizarse periódicamente los Indicadores de fraude comercial sería inestimable.

15. La reunión oficiosa de expertos sugirió que entre los defraudadores comerciales había coordinación, educación y cooperación y que esfuerzos similares eran esenciales para prevenir y combatir el fraude comercial.

16. En la reunión se puso de relieve la necesidad de que los especialistas dedicados a combatir el fraude comercial tuvieran la oportunidad de reunirse periódicamente para intercambiar información. En vista de los recursos limitados de que disponía la CNUDMI, se sugirió que podría alentarse a organizaciones privadas a que continuaran las actividades de lucha contra el fraude en el futuro mediante la cooperación oficiosa con la CNUDMI y el aliento y apoyo que esta pudiera prestarles.

17. La reunión oficiosa de expertos recomendó que se prestara atención al fomento de la coordinación, la educación continua y la capacitación por otras organizaciones.

IV. Recomendaciones para el examen por la Comisión

18. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la reunión oficiosa de expertos sugirió que sería útil que la CNUDMI, en consulta con la UNODC, organizara un coloquio sobre los siguientes temas:

a) El fraude comercial en el panorama tecnológico emergente, inclusión hecha de:

- i) El robo de la identidad de empresas;
 - ii) Las repercusiones del fraude comercial en la computación en nube y su uso indebido;
 - iii) El abuso de los pagos móviles, incluidos sus efectos en las iniciativas de microfinanciación;
 - iv) El abuso de la solución de controversias en línea por los defraudadores;
- b) La repercusión de la crisis financiera mundial en el fraude comercial;
- c) Las amenazas emergentes del fraude comercial para el comercio mundial;
- d) El respaldo, la promoción y la actualización de los Indicadores;

¹¹ Documento A/CN.9/555, párr. 63.

¹² *Ibid.*

e) La determinación de la labor que se lleva a cabo actualmente para combatir el fraude comercial y el examen de proyectos en las esferas tratadas en el Coloquio de 2004, en particular el fraude bancario y comercial, el fraude cibernético, el fraude de valores y la prevención del fraude; y

f) La viabilidad y conveniencia de la coordinación oficiosa para continuar las oportunidades de coordinación.

F. Propuesta del Gobierno de los Estados Unidos relativa a la labor futura de la CNUDMI: Tema 16 del programa provisional¹

(A/CN.9/789)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1
II. Propuesta del Gobierno de los Estados Unidos.	

I. Introducción

1. En el 46º período de sesiones de la Comisión se examinará, en relación con el tema 16 del programa provisional, la labor prevista y la posible labor futura de la CNUDMI, para lo que se dispondrá de una nota de la Secretaría (A/CN.9/752 y Add.1) y de otra nota de la Secretaría sobre la labor prevista y la posible labor futura de la CNUDMI (A/CN.9/774). A ese respecto, el Gobierno de los Estados Unidos de América ha presentado una propuesta relativa a la labor futura de la CNUDMI, cuyo texto se reproduce a continuación en la forma en que ha sido recibido por la Secretaría.

II. Propuesta del Gobierno de los Estados Unidos

Los Estados Unidos agradecen mucho las notas preparadas por la Secretaría sobre la labor prevista y la posible labor futura², concebidas para señalar a la atención de los Estados las importantes preocupaciones relativas a las prioridades y las limitaciones de recursos de la organización. Los Estados Unidos han apoyado sistemáticamente que se proporcionen recursos suficientes para sostener la importante labor que lleva a cabo la CNUDMI que, a nuestro juicio, ha sido uno de los órganos más productivos del sistema de las Naciones Unidas. El elevado nivel de la documentación que produce la secretaría de la CNUDMI para todas las reuniones es incluso más notable si se considera el reducido número de funcionarios que trabajan en la secretaría y el inmenso ámbito de la labor de que se ocupa la CNUDMI. Es lamentable que, como se informó en el último período de sesiones de la Comisión, “la CNUDMI, con los recursos actualmente disponibles, no puede seguir generando

¹ El tema 16 del programa provisional se titula “Labor prevista y posible labor futura, entre otras cosas en los ámbitos del arbitraje y la conciliación, el fraude comercial, el comercio electrónico, el régimen de la insolvencia, el derecho contractual internacional, la microfinanciación, la solución de controversias por vía informática, la contratación pública y el desarrollo de infraestructuras, incluida la colaboración entre el sector público y el sector privado, y las garantías reales.” Documento de las Naciones Unidas A/CN.9/759 (2013).

² Notas de la Secretaría, Un rumbo estratégico para la CNUDMI, documento de las Naciones Unidas A/CN.9/752 y Add.1 (2012); Labor prevista y posible labor futura, documento de las Naciones Unidas A/CN.9/774 (2013).

textos jurídicos al ritmo actual y contribuir en el grado necesario a la aplicación y utilización de todos los textos de la CNUDMI³.”

En su período de sesiones celebrado en 2012, la Comisión tomó nota de las siguientes consideraciones estratégicas:

- a) Los sectores que debían considerarse de máxima prioridad, en relación con el papel y de la importancia de la CNUDMI;
- b) El logro de un equilibrio óptimo de actividades, habida cuenta de los recursos de que se disponía;
- c) La sostenibilidad del método actual, es decir, el hecho de que se diera más importancia a las negociaciones oficiales que a las oficiosas al elaborar textos, habida cuenta de los recursos de que se disponía;
- d) La movilización de recursos suplementarios y la cuestión de si la CNUDMI debería solicitar recursos externos para desempeñar sus funciones, por ejemplo, mediante actividades conjuntas y la cooperación con otros órganos⁴.

La Comisión convino en “examinar esas cuestiones, entre otras cosas, y dar orientación al respecto en su 46º período de sesiones⁵.”

Sostenibilidad del método actual

Desde hace algunos años, los Estados han propuesto que la CNUDMI adopte un enfoque más flexible de los métodos de trabajo para atender las preocupaciones relacionadas con los recursos y velar por que los proyectos de máxima prioridad y más valiosos puedan seguir adelante⁶. La Secretaría ha sugerido que tal vez podría encomendarse más de un tema a un grupo de trabajo concreto. Proponemos que otra forma de lograr un plan de trabajo más flexible podría consistir en que la CNUDMI se concentrara en autorizar determinados proyectos y asignarles los recursos necesarios, en lugar de mantener seis grupos de trabajo que por lo general se dedican exclusivamente a una esfera del derecho durante muchos años. Así pues, sugerimos que la CNUDMI deje de estructurar sus prioridades de trabajo mediante un sistema de seis grupos de trabajo semipermanentes dedicados a una esfera concreta del derecho, a cada uno de los cuales se ha de otorgar en teoría dos semanas de tiempo de reuniones cada año⁷.

³ A/CN.9/752/Add.1, párr. 25.

⁴ Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 45º período de sesiones (25 de junio a 6 de julio de 2012), documento de las Naciones Unidas A/67/17, párr. 229.

⁵ Íd., párr. 231.

⁶ Véase, por ejemplo, el informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 44º período de sesiones (27 de junio a 8 de julio de 2011), documento de las Naciones Unidas A/66/17, párr. 343.

⁷ En su período de sesiones celebrado en 2003, la Comisión convino en que los grupos de trabajo se reunieran durante un período de sesiones de una semana dos veces al año, pero que se podía asignar tiempo adicional a un grupo de trabajo si otro no utilizaba todo el tiempo al que tenía derecho. Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 36º período de sesiones (30 de junio a 11 de julio de 2003), documento de las Naciones Unidas A/58/17, párrs. 273 y 275.

Por ejemplo, en lugar de contar con una entidad permanente denominada “Grupo de Trabajo IV – Comercio electrónico”, la Comisión aprobaría la continuación del trabajo en el instrumento en vías de elaboración sobre los documentos transmisibles electrónicos y determinaría los recursos que el proyecto vaya a necesitar durante el año siguiente (por lo que se refiere a la atención que le prestaría la Secretaría y a los recursos para conferencias). Teniendo en cuenta que la CNUDMI tiene derecho en la actualidad a 14 semanas de servicios de conferencias (con inclusión del espacio para reuniones y la interpretación)⁸, esos recursos podrían asignarse a proyectos concretos en función de las necesidades en lugar de dar por sentado, como regla general, que cada grupo de trabajo dedicado a un tema concreto reciba dos semanas de tiempo de reuniones. (Más abajo se presenta una propuesta de asignación de recursos para el año siguiente.)

Con este enfoque, la Comisión tendría que evaluar si los temas que se están tratando seguirían teniendo la máxima prioridad cuando se disponga nuevamente de recursos tras la finalización de un proyecto. En cambio, el empleo de grupos de trabajo semipermanentes que proponen sus propias esferas futuras de trabajo supone que tan solo en raras ocasiones estimará uno de esos grupos que su labor provechosa se ha agotado. Es comprensible que los especialistas en cada ámbito del derecho sigan creyendo a menudo que se puede continuar realizando una labor valiosa en su esfera de especialización. Aunque efectivamente ese fuera el caso, esa labor tal vez no resulte más útil- en lo que se refiere a fomentar el mandato de la CNUDMI -que una nueva labor en esferas que actualmente no tienen la suerte de que se les haya asignado un grupo de trabajo. Dada la escasez de recursos, la CNUDMI no puede permitirse seguir funcionando en el supuesto implícito de que la conclusión de un proyecto en una esfera del derecho irá seguida de más trabajo sobre el mismo tema.

Como otro método de conservar recursos, también opinamos que la Comisión debería examinar, en los casos en que proceda, la elaboración de proyectos de instrumentos fuera de las deliberaciones intergubernamentales plenas que utilizan los grupos de trabajo. Por supuesto, el examen oficial por los Estados Miembros de la Comisión es necesario para la aprobación y finalización de todo instrumento. Sin embargo, anteriormente, la propia Comisión ha examinado en ocasiones un texto elaborado por la Secretaría (con aportaciones de expertos) sin negociaciones previas en el contexto de un grupo de trabajo⁹. Los Estados Unidos instan a la CNUDMI a que estudie la posibilidad de utilizar un enfoque de esa índole cuando proceda, junto

⁸ Los Estados Unidos no apoyan una nueva reducción de la asignación de recursos para conferencias. En su período de sesiones celebrado en 2011, la Comisión convino en una reducción del total habitual de 15 semanas anuales a que tenía derecho en vista de las extraordinarias limitaciones impuestas a la Comisión y a su secretaría para reducir los gastos del presupuesto ordinario durante el bienio 2012-2013. Informe sobre el 44º período de sesiones, nota 6 *supra*, párr. 347.

⁹ Véase Un rumbo estratégico para la CNUDMI, *supra* nota 2, párr. 33 (en el que se observa que “la Secretaría ha emprendido la elaboración sustantiva de un texto en varias ocasiones”, por ejemplo, “cuando un proyecto de texto fue elaborado por la Secretaría y remitido directamente a la Comisión al no existir ningún grupo de trabajo que tuviera los conocimientos especializados pertinentes (por ejemplo, la Guía Jurídica sobre Transferencias Electrónicas de Fondos (1987) y la Guía Legislativa sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada (2000)” y cuando “la preparación del proyecto de texto se encomendó a la Secretaría y se remitió directamente a la Comisión (por ejemplo, las Recomendaciones sobre el uso del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (2012))”).

con otras herramientas como, por ejemplo, la utilización más amplia de reuniones de expertos, reuniones regionales (incluidas aquellas en que se pueda disponer de recursos del gobierno anfitrión), y la utilización de relatores especiales que, en estrecha colaboración con la Secretaría, podrían facilitar la preparación de proyectos de documentación para su examen¹⁰.

Movilización de recursos suplementarios

Los Estados también han reconocido que, como una herramienta más para ocuparse de nuevas esferas de trabajo eficientemente, la CNUDMI debería procurar intensificar la cooperación con otras organizaciones internacionales, de forma compatible con su mandato principal¹¹. Un enfoque de la asignación de recursos basado en los proyectos, como el que acaba de exponer, facilitaría que la CNUDMI participara en proyectos conjuntos con otras organizaciones como el UNIDROIT o la Conferencia de La Haya, ya que para entablar esa colaboración no habría necesidad de esperar a que un grupo de trabajo existente quedara “vacante”. Dado que esos otros órganos que se ocupan del derecho privado se enfrentan a limitaciones de recursos similares, las tres organizaciones deberían analizar sus programas de trabajo a fin de concretar proyectos que pudieran elaborarse conjuntamente. De hecho, en la reunión del Consejo de Administración celebrada este año, el UNIDROIT dio su firme apoyo a la idea de una cooperación sustantiva con la CNUDMI en proyectos futuros, en los que las dos organizaciones elaborarían instrumentos conjuntamente.

Pensando en el futuro, creemos que la CNUDMI debería otorgar prioridad a esa colaboración. Acogemos con satisfacción los recientes esfuerzos encaminados a la cooperación, como la publicación conjunta del documento titulado “Textos sobre garantías reales preparados por la CNUDMI, la Conferencia de La Haya y el UNIDROIT”¹². No obstante, creemos que la colaboración no debería limitarse a estudios conjuntos y a que funcionarios de la Secretaría asistieran a las reuniones de las demás organizaciones. Antes bien, recomendamos que las secretarías de las respectivas organizaciones procuren concretar proyectos que pudieran elaborarse conjuntamente, aprovechando al máximo las ventajas comparativas de cada organización.

Temas a los que debería otorgarse la máxima prioridad

Por lo que se refiere a la evaluación de la labor futura, la Comisión ha decidido en repetidas ocasiones que la evaluación de proyectos específicos se basara en la necesidad de la labor futura y su viabilidad, en la medida en que guarde relación con

¹⁰ Véase Nota de la Secretaría, Reglamento y métodos de trabajo de la CNUDMI, A/CN.9/638/Add.1, párrs. 31 a 33, 36 a 42 (2007).

¹¹ Véase Establecimiento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, A/RES/2205 (17 de diciembre de 1966), párr. 8 (“La Comisión fomentará la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional mediante: a) La coordinación de la labor de las organizaciones que realizan actividades en este campo y el estímulo de la colaboración entre ellas...”).

¹² Véase el informe del 45º período de sesiones, *supra* nota 4, párrs. 165 y 166.

el desarrollo del derecho mercantil internacional¹³. Para evaluar la necesidad en ese contexto, un criterio fundamental es el efecto que una propuesta vaya a tener en el desarrollo económico inclusivo y el estado de derecho, en particular en los países en desarrollo¹⁴. Como también ha decidido la Comisión, “por norma general, la Comisión no debía remitir temas a un grupo de trabajo sino después de que la Secretaría hubiese realizado estudios preparatorios y el examen de esos estudios por la Comisión hubiese indicado que el tema era no sólo adecuado sino que además la labor preparatoria estaba suficientemente avanzada para que un grupo de trabajo iniciase su labor de manera fructífera¹⁵.”

Asignación de recursos a los proyectos

Teniendo en cuenta las reflexiones mencionadas, y suponiendo que se disponga nuevamente de 14 semanas de tiempo de reuniones, los Estados Unidos proponen que los recursos se asignen de la siguiente forma en el año venidero:

<i>Proyecto</i>	<i>Asignación de tiempo de reuniones</i>
Labor de seguimiento sobre la transparencia, según proceda, y/o nuevos temas de arbitraje	Dos semanas
Preparación de normas jurídicas para la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico	Dos semanas
Elaboración de un instrumento sobre los documentos transmisibles electrónicos	Dos semanas
Preparación de una ley modelo sobre las operaciones garantizadas	Dos semanas
Elaboración de una guía legislativa o una ley modelo sobre la creación de un entorno propicio para las microempresas y las empresas pequeñas y medianas (microfinanzas)	Dos semanas

¹³ Como señala la Secretaría (A/CN.9/774, párr. 19), el interés en la necesidad y la viabilidad se retrotrae al primer informe del Secretario General sobre la formación de la CNUDMI. Informe del Secretario General, A/6396 (1966). En dicho informe se observa que “el proceso de unificación no siempre es aconsejable de por sí: sólo es apetecible cuando hay una necesidad económica y las medidas unificadoras han de redundar en provecho del desarrollo del comercio internacional”. Íd., párr. 204. También se ocupa de la viabilidad, observando que “[p]or ello adaptar las normas nacionales a las necesidades del comercio internacional sería menos difícil que la unificación de normas sobre materias como el derecho de familia, la sucesión, la condición jurídica de la persona y otras materias hondamente arraigadas en las tradiciones nacionales o religiosas”. Íd., párr. 222.

¹⁴ La función que desempeña la CNUDMI en el fomento del estado de derecho ha figurado en el programa de la Comisión desde 2008, atendiendo a una solicitud de la Asamblea General. En 2012, la CNUDMI participó en una reunión de alto nivel de la Asamblea General, en la que se puso de relieve la función que desempeñaba la CNUDMI en el fomento del estado de derecho. Véase el informe del 45º período de sesiones, *supra* nota 4, párrs. 195 a 227.

¹⁵ Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 11º período de sesiones (30 de mayo a 6 de junio de 1978), documento de las Naciones Unidas A/33/17, párrs. 67 y 68; Nota de la Secretaría, Reglamento y métodos de trabajo de la CNUDMI, A/CN.9/638, párr. 20 (2007).

<i>Proyecto</i>	<i>Asignación de tiempo de reuniones</i>
Coloquio sobre la insolvencia transfronteriza para determinar proyectos concretos de la labor futura (inclusión hecha de proyectos relativos a temas generales ya en vías de examen	Media semana
Coloquio sobre el fraude comercial	Media semana
Redacción de una ley modelo sobre la colaboración entre el sector público y el sector privado	Ninguna reunión – trabajo de la Secretaría y los expertos
Reunión de 2014 de la Comisión, incluido el examen de la labor de la Secretaría y los expertos acerca de una ley modelo sobre la colaboración entre el sector público y el sector privado (si procede)	Tres semanas

En el documento de la Secretaría se sugiere la posible reducción de los seis grupos de trabajo existentes a cinco. Sin embargo, opinamos que la utilización del enfoque más flexible antes reseñado -asignándose recursos a proyectos concretos antes que a grupos de trabajo semipermanentes- tal vez permitiese a la CNUDMI conservar recursos sin eliminar temas útiles. Únicamente cinco proyectos serían objeto de negociaciones intergubernamentales plenas, reduciendo así la carga para la Secretaría; al mismo tiempo, la CNUDMI podría seguir dedicándose a otras materias y realizando los preparativos necesarios para poner en marcha nuevos proyectos en el futuro.

La asignación de recursos que se propone entrañaría un enfoque algo diferente de varias esferas en que se ha propuesto que comiencen nuevos trabajos o continúen los que ya están en marcha, entre otras cosas mediante la aplicación de algunos de los métodos de trabajo más flexibles expuestos anteriormente. A continuación se analizan las repercusiones en proyectos concretos.

Microfinanzas y temas conexos

De conformidad con la decisión adoptada por la Comisión en su último período de sesiones y la recomendación del coloquio sobre las microfinanzas y temas conexos celebrado en enero de 2013, creemos, en concordancia con la propuesta presentada por el Gobierno de Colombia, se debería iniciar la labor sobre una guía legislativa o una ley modelo que se ocupe de los elementos necesarios para la creación de un entorno jurídico propicio en relación con el ciclo de vida de las microempresas y las pequeñas empresas: simplificación de los procedimientos de constitución en sociedades, solución de controversias, acceso al crédito, pagos por medios móviles e insolvencia.

En su 45º período de sesiones, la Comisión decidió que la celebración de un segundo coloquio sobre las microfinanzas “debería revestir la máxima prioridad para la CNUDMI¹⁶.” La Comisión decidió que el coloquio se centrara en “la facilitación de la constitución y el registro simplificados de empresas; el acceso al crédito para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas; la solución de controversias aplicable a operaciones microfinancieras; y otros temas relacionados con la creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y

¹⁶ Informe del 45º período de sesiones, *supra* nota 4, párr. 126.

pequeñas y medianas empresas¹⁷.” En el coloquio, celebrado en enero de 2013, hubo “amplio consenso entre los participantes” en recomendar que la CNUDMI “se encargara de examinar los aspectos jurídicos necesarios para la creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Se subrayó que la labor encaminada a crear ese tipo de condiciones sería conforme con el mandato principal de la Comisión de promover la coordinación y cooperación en la esfera del comercio internacional, incluido el comercio transfronterizo regional¹⁸.”

En la nota de la Secretaría se subraya la fundamental importancia que reviste establecer un entorno jurídico propicio para que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo puedan acceder a los mercados internacionales a través del comercio electrónico y el comercio con dispositivos móviles¹⁹. Además, “[l]a creación de condiciones jurídicas propicias también contribuye a reforzar el estado de derecho a nivel de los países, lo que, como destacó la Asamblea General en su resolución sobre el estado de derecho, permite el crecimiento de un sistema justo, estable y previsible para generar un desarrollo inclusivo, sostenible y equitativo²⁰.” Así pues, en concordancia con la recomendación del coloquio, creemos que debería iniciarse la labor sobre una guía legislativa o una ley modelo que se ocupe de esos temas²¹.

Insolvencia

Los Estados Unidos sugieren se organice un coloquio para determinar proyectos concretos y posibles esferas de la labor futura en lugar de reuniones intergubernamentales plenas sobre la insolvencia durante el año próximo. Luego, en

¹⁷ *Íd.*

¹⁸ Nota de la Secretaría, Microfinanciación: creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, A/CN.9/780, párr. 50 (2013). En la nota de la Secretaría se puntualiza que “el reconocimiento transfronterizo de estas nuevas y variadas cuestiones legislativas y estructuras emergentes [es] necesario para que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas [puedan] operar en los mercados regionales a fin de aportar un fundamento internacional reconocible para las operaciones y evitar los problemas que [puedan] surgir a resultados de la falta de reconocimiento comercial.” *Íd.*

¹⁹ *Íd.*, párr. 52 (observando que “[e]n todo el mundo, el uso de Internet ha aumentado el 528% en el último decenio: aproximadamente la tercera parte de la población mundial está actualmente conectada a Internet” y que “[s]e espera que ese número aumente al 47% para 2016); véase también la nota de la Secretaría, Posible labor futura sobre la solución en línea de controversias surgidas en operaciones de comercio electrónico transfronterizas, documento de las Naciones Unidas A/CN.9/706, párr. 9 (2010) (observando que “[u]no de los principales factores que impulsan el desarrollo del comercio electrónico es el creciente número de personas conectadas a Internet.”).

²⁰ Microfinanzas, *supra* nota 18, párr. 13 (se omite la nota de pie de página).

²¹ Con respecto al informe del Secretario General que se menciona en la anterior nota de pie de página 13, se citan algunos aspectos del derecho de sociedades que afectan al comercio internacional como un ejemplo de la labor que podría llevarse a cabo. Documento de las Naciones Unidas A/6396, párr. 207 (en el que se señala que “sería beneficioso para el comercio internacional el que se hicieran nuevos intentos encaminados a ... las normas relativas a las corporaciones que intervienen en transacciones de comercio exterior”). La Asamblea General también solicitó a la CNUDMI que emprendiera una labor sobre los problemas jurídicos que presentaban los diversos tipos de empresas multinacionales. Véase resolución 2928 de la Asamblea General, A/RES/2928 (XXVII), párr. 5 (1972).

el marco del enfoque flexible de la asignación de recursos que se ha indicado en la primera sección del presente documento, podría reanudarse la labor sobre la insolvencia una vez que la Comisión haya determinado y aprobado un proyecto concreto adecuado.

En cuanto a la insolvencia, el Grupo de Trabajo V ya ha finalizado los dos proyectos a los que ha venido dedicando su tiempo durante varios de los últimos años. Ha ultimado un conjunto de revisiones de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza y también ha terminado una nueva sección de texto para la Guía Legislativa sobre la Insolvencia. Esos dos documentos se van a presentar a la Comisión para su finalización y aprobación. En el informe más reciente del Grupo de Trabajo V se señala que, aunque el Grupo de Trabajo tal vez no haya agotado su mandato desde el punto de vista técnico en lo que se refiere a las cuestiones jurídicas de que cabría ocuparse, no cuenta con un plan para lo que emanaría de su labor sobre esos temas²². Por lo tanto, el Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que un coloquio podría ser útil para determinar los futuros proyectos (sobre temas ya proyectados así como sobre otros temas propuestos) que podrían ser más útiles²³.

Estamos de acuerdo con la conclusión del Grupo de Trabajo V de que un coloquio sería apropiado; los valiosos instrumentos que ha elaborado el Grupo de Trabajo en esta esfera del derecho han tenido muchísima influencia, y la CNUDMI debería plantearse otros proyectos en los que se pudiera aprovechar la extraordinaria pericia de los delegados y observadores que han participado en esas actividades. Sin embargo, en vista de la incertidumbre reinante sobre los proyectos concretos que podrían prestarse a una labor inmediata, no creemos que las reuniones del grupo de trabajo vayan a constituir una utilización prudente de recursos cada vez más escasos mientras se concretan esos proyectos.

Colaboración entre el sector público y el sector privado

Si bien es cierto que una nueva labor sobre la colaboración entre el sector público y el sector privado podría ser provechosa, se puede impulsar mediante otros métodos de trabajo dirigidos por la Secretaría. Un enfoque de esa índole sería compatible con la práctica de la Comisión, que tan buenos resultados ha dado, al elaborar la Guía

²² Informe del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) sobre la labor realizada en su 43º período de sesiones (Nueva York, 15 a 19 de abril de 2013), documento de las Naciones Unidas A/CN.9/766, párr. 108 (en el que se observa que, aunque el Grupo de Trabajo “aún no había concluido su labor relativa a la aplicación del mandato encomendado por la Comisión”, no obstante “aún no estaba claro cuál era el modo más indicado de cumplir esa parte del mandato”).

²³ Íd. (“El Grupo de Trabajo escuchó una propuesta de celebración de un coloquio para examinar el modo en que podía cumplir la parte restante del mandato y el tipo de instrumento más adecuado para hacerlo, así como para determinar posibles temas de los que cabría ocuparse en el futuro. El Grupo de Trabajo convino en que un coloquio de esas características podría ser útil; no obstante, la sugerencia de que se celebrara en lugar de los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo necesarios para concluir el mandato otorgado por la Comisión no atrajo un apoyo suficiente. Varias delegaciones sugirieron que se procurara obtener la aprobación de la Comisión para cualesquiera proyectos futuros, pero esa opinión no logró apoyo suficiente.”).

Legislativa de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública²⁴.

En mayo de 2013, la CNUDMI organizó un coloquio sobre cuestiones relacionadas con la colaboración entre el sector público y el sector privado para examinar la posible utilidad de una labor futura que ampliaría los instrumentos estrechamente vinculados que ha producido anteriormente el Grupo de Trabajo I -a saber, la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada (que incluye un conjunto de recomendaciones legislativas) y un conjunto de Disposiciones Legales Modelo sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada. En el coloquio se llegó a la conclusión de que, en vista de la utilización creciente de la colaboración entre el sector público y el sector privado y las novedades de los últimos años, podría ser útil continuar la labor en esa esfera. El tema más probable para un proyecto futuro será una ley modelo, que, según señalaron muchos participantes en el coloquio, tendría mayor visibilidad -y sería más fácil de promocionar- que los instrumentos existentes.

Debido a la labor que ya se ha realizado sobre recomendaciones legislativas y disposiciones legislativas modelo, podría prepararse una ley modelo básica sin el desembolso de recursos que supondrían unas negociaciones intergubernamentales plenas en un grupo de trabajo. Como se ha indicado anteriormente, así como en el documento de la Secretaría, la elaboración de un texto fuera de un grupo de trabajo -con su subsiguiente examen por la Comisión- podría permitir que la CNUDMI elevara su productividad al máximo pese a las graves limitaciones de recursos. Teniendo en cuenta las deliberaciones mantenidas en el coloquio, los Estados Unidos creen que ese enfoque sería el método ideal para elaborar una ley modelo sobre la colaboración entre el sector público y el sector privado. Como la Comisión ya ha aprobado los instrumentos elaborados por el Grupo de Trabajo I, que abarcan la mayor parte de las cuestiones de que tendría que ocuparse una ley modelo, lo principal que queda por hacer es meramente una actividad técnica de redacción. El proyecto de una ley modelo podría elaborarse por conducto de un grupo de expertos dirigido por la Secretaría; luego, en un período de sesiones de la Comisión, los Estados Miembros podrían examinar el documento y efectuar los retoques necesarios para finalizarlo o, de ser necesario, remitirlo para que se siguiera elaborando.

Fraude comercial

Damos nuestro apoyo a la organización de un coloquio sobre fraude comercial en coordinación con la UNODC, como se propuso en el último período de sesiones de la Comisión²⁵. En la reunión oficiosa de expertos que organizó la CNUDMI sobre el fraude comercial, celebrada en abril de 2013, se expresó amplio apoyo a la

²⁴ Como se ha indicado anteriormente, *supra* nota 9, la Secretaría elaboró un proyecto de texto que fue remitido directamente a la Comisión relativo a la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada (2000). En el período de sesiones de la Comisión celebrado en 2011, los Estados pidieron que se recurriera a “grupos de redacción para ultimar los textos, como se había hecho con buenos resultados durante el actual período de sesiones respecto de la Ley Modelo sobre la Contratación Pública.” Informe del 44º período de sesiones, *supra* nota 6, párr. 343.

²⁵ Informe del 45º período de sesiones, *supra* nota 4, párr. 232.

celebración de otro coloquio como complemento del Coloquio de 2004 y a la actualización de la labor que la CNUDMI ya había realizado sobre los indicadores de fraude comercial²⁶. Se expresó la extendida opinión de que, dada la función vital que desempeñaba el sector privado en la lucha contra el fraude comercial, la CNUDMI se encontraba en una situación privilegiada para coordinar los esfuerzos que se llevaban a cabo al respecto y para avisar a los legisladores y a las autoridades normativas acerca de los importantes problemas que creaba esa cuestión²⁷. En particular, se observó que los adelantos de las telecomunicaciones electrónicas planteaban nuevos problemas y que las consecuencias de esas nuevas situaciones afectaban a todos los aspectos de la actividad empresarial, financiera y comercial. También se sugirió que tal vez fuera útil concentrarse por separado en las posibilidades de fraude comercial en las esferas a que se dedicaban actualmente los Grupos de Trabajo de la CNUDMI, como la solución de controversias en línea y la transmisión electrónica de documentos. Aunque en esos textos se trate de abordar cuestiones de fraude, puede que el tipo de conocimientos especializados necesarios para formular reglas normativas de derecho mercantil en esas esferas no sea necesariamente el mismo que se necesita para determinar posibilidades de fraude comercial y la forma de combatirlos en un instrumento²⁸.

Derecho contractual internacional

También apoyamos la organización de un coloquio para conmemorar el 35º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CIM) en 2015. En el Coloquio de la CNUDMI celebrado en 2005 para conmemorar el 25º aniversario de la CIM se reconoció que la Convención era probablemente el tratado que mejores resultados había dado en la historia del derecho mercantil moderno²⁹. Desde que se celebró ese coloquio, otros 16 Estados han pasado a ser partes en la Convención, con lo que el número total de partes asciende ya a 79³⁰.

En una propuesta presentada en el último período de sesiones de la Comisión se pidió que se estudiara la posibilidad de lanzar una nueva iniciativa a nivel mundial sobre el derecho contractual internacional³¹. Varias delegaciones, entre ellas la de

²⁶ Nota de la Secretaría, Fraude comercial, A/CN.9/788, párrs. 8 a 12, 18 (2013).

²⁷ Íd., párrs. 13 a 17.

²⁸ Íd., párr. 11. En el período de sesiones de la Comisión celebrado en 2004 (a continuación del Coloquio internacional sobre el fraude comercial) se decidió que “sería conveniente que, cuando procediera, [la Comisión] estudiara ejemplos de fraude comercial al examinar proyectos concretos, a fin de que las delegaciones que se ocuparan de esos proyectos pudieran tener en cuenta el problema del fraude en sus deliberaciones. Se pidió a la Secretaría que siempre que fuera oportuno facilitara esos debates.” Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 37º período de sesiones (14 a 25 de junio de 2004), documento de las Naciones Unidas A/59/17, párr. 111.

²⁹ Herbert Kronke, *The UN Sales Convention, the UNIDROIT Contract Principles and the Way Beyond*, 25 J. L. & Comm. 451 (2005).

³⁰ Véanse las partes en la CIM en Situación actual, 1980 – Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, que puede consultarse en www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html.

³¹ Posible labor futura en material de derecho contractual internacional: Propuesta de Suiza sobre la posible labor futura de la CNUDMI en materia de derecho contractual internacional, documento de las Naciones Unidas A/CN.9/758 (2012).

los Estados Unidos, se opusieron decididamente a que se emprendiera una labor sobre un nuevo marco mundial del derecho contractual internacional. No obstante, se solicitó a la Secretaría “que organizara simposios y otras reuniones ... que sirviera[n] de ayuda a la Comisión para determinar la conveniencia y viabilidad de emprender una labor futura en materia del derecho general de los contratos³².” Para cumplir ese mandato, la CNUDMI copatrocinó un simposio en enero de 2013 en la Villanova Law School sobre la evaluación de la CIM y otras actividades internacionales para unificar el derecho contractual internacional, y celebró en febrero de 2013 una reunión de expertos en derecho contractual en el Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico³³.

Sobre la base de las deliberaciones mantenidas en esas reuniones, los Estados Unidos siguen oponiéndose a una nueva iniciativa en materia de derecho contractual internacional a nivel mundial, ya que una iniciativa de la escala que se propone sería un proyecto ingente, que consumiría cuantiosos recursos durante muchos años, con escasas probabilidades de éxito. El ámbito de aplicación de la CIM se limitó intencionadamente para excluir cuestiones sobre las que no pudo llegarse a un consenso, y no hemos visto ninguna prueba de que esas diferencias hayan cambiado fundamentalmente en los últimos años. Además, los Principios sobre los contratos comerciales internacionales del UNIDROIT ya constituyen un valioso complemento de la CIM. En sus períodos de sesiones de 2007 y 2012, la Comisión hizo suyos los Principios sobre los contratos del UNIDROIT, recomendando su utilización con los fines a que se destinaban, señalándolos como complemento de la CIM y felicitando al UNIDROIT por preparar “normas generales sobre los contratos comerciales internacionales³⁴.” Por tanto, creemos que existen otras soluciones más prácticas, positivas y con mayor visión del futuro cimentadas en la plataforma existente de la CIM y los Principios del UNIDROIT y que la CNUDMI debería concentrar su atención en esas otras soluciones.

³² En el informe del 45º período de sesiones, *supra* nota 4, párrs. 127 a 132, figura un resumen del debate.

³³ Se puede consultar información sobre el simposio en www.law.villanova.edu/Flash%20Stories/Norman%20J%20Shachoy%20Symposium.aspx. Los textos relacionados con el simposio se publicarán en el número 58:4 de la Villanova Law Review. Los documentos relacionados con la reunión regional de expertos celebrada en Songdo, Incheon (República de Corea) se publicarán en un número del Comparative Law Journal of the Pacific – Journal de Droit Comparé du Pacifique (CLJP-JDCP).

³⁴ Informe del 45º período de sesiones, *supra* nota 4, párr. 140; Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 40º período de sesiones (25 de junio a 12 de julio de 2007), documento de las Naciones Unidas A/62/17 (Part I), párr. 213.

G. Propuesta del Gobierno de Colombia

(A/CN.9/790)

[Original: español]

Nota de la Secretaría

En su 46º período de sesiones, la Comisión tal vez desee examinar punto 16 del programa previsional (Labor prevista y posible labor futura, entre otras cosas en los ámbitos del arbitraje y la conciliación, el fraude comercial, el comercio electrónico, el régimen de la insolvencia, el derecho contractual internacional, la microfinanciación, la solución de controversias en línea, la contratación pública y el desarrollo de infraestructuras, incluida la colaboración entre el sector público y el sector privado, y las garantías reales). La Comisión tendrá a su disposición una nota de la Secretaría, sobre la labor prevista y la posible labor futura de la CNUDMI (A/CN.9/774). En ese ámbito, el Gobierno de Colombia presentó una propuesta cuyo texto se reproduce a continuación tal como lo recibió la Secretaría.

Anexo

Propuesta de establecimiento de un nuevo grupo de trabajo en “Microfinanza y asuntos relacionados: creación de un ambiente legal propicio para las micro, pequeñas y medianas empresas”

I. Introducción

La CNUDMI aprobó en su sesión plenaria 45º la propuesta del Gobierno de Colombia para la celebración de un Segundo Coloquio en microfinanza, con énfasis en la simplificación y flexibilización del registro e incorporación de sociedades mercantiles¹.

En la propuesta el Gobierno de Colombia planteó que uno de los aspectos cruciales en el campo de la microfinanza, además del otorgamiento del crédito, era la creación de vehículos corporativos empresariales simplificados que promovieran la formalización y transparencia de los destinatarios de los microcréditos. En este tema se establece un claro campo de acción para la CNUDMI por tratarse de una materia propia del derecho comercial.

La Comisión decidió “que la celebración de un coloquio de esa índole debería revestir la máxima prioridad para la CNUDMI”². El Coloquio en microfinanza y asuntos relacionados fue celebrado en enero de 2013 y en él participaron expertos y especialistas, representantes de gobierno, de organizaciones internacionales,

¹ Superintendencia de Sociedades, Oficio 2012-01-17-0670, dirigido de Renaud Sorieul, Secretario de CNUDMI, 2012/06/21.

² UN Doc. A/67/17- Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil internacional 45º período de sesiones (25 de junio a 6 de julio de 2012), párr.126 disponible en: <http://www.uncitral.org/uncitral/connmission/sessions/45th.html>.

organizaciones no gubernamentales, del sector privado y de la academia provenientes de todo el mundo³.

La conclusión más importante del Coloquio fue que la CNUDMI debería establecer un grupo nuevo de trabajo en microfinanza y asuntos relacionados. La Secretaría resumió el resultado del Coloquio así:

“...There was broad consensus among participants at the Colloquium recommending that a Working Group be established to address the legal aspects necessary for the creation of an enabling legal environment for MSMEs. It was stressed that work in establishing such an environment would be consistent with the Commission’s primary mandate to promote coordination and cooperation in the field of international trade, including regional cross-border trade⁴.”

II. La importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en países en desarrollo

En una economía en desarrollo, las pequeñas y micro empresas constituyen el tejido empresarial y forman la base de las medianas y grandes empresas. El establecimiento de estas últimas estará dado por la solidez con la que las pequeñas y micro empresas se integren a un proceso formal de operación en sus negocios⁵.

Los gobiernos deberán adelantar políticas públicas y enfocar sus esfuerzos para fortalecer el sector empresarial⁶, pero tal vez y de mayor relevancia, propender por la creación de un ambiente legal propicio diseñado a la medida de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Una consideración importante en la creación de ese ambiente legal propicio es el efecto que este tendría tanto en la microfinanza como en la microempresa. En el informe presentado por la Secretaría se resalta esa importancia así:

“In order to help micro, small and medium-sized enterprises to adjust to immediate uncertainty, and graduate from a subsistence form of doing business to a growth mode characteristic of the formal sector, an enabling legal environment is thus needed. Such an environment is not limited to microfinance alone; it relates to the life cycle of a business its establishment, operation and termination — and it also focuses on the supporting institutional legal framework. Nonetheless it is clearly relevant to microfinance since, “as a market-based approach to fighting poverty, microfinance is focused on developing entrepreneurship and expanding self-employment”⁷. Furthermore, an enabling legal environment should not be

³ Realizado por la Secretaría de la CNUDMI se hacen en idioma inglés, toda vez que al momento de su elaboración no se contó con el texto oficial en idioma español. Microfinance: creating an enabling legal environment for micro-business and small and medium-sized enterprises Note by the Secretariat, A/CN.9/780, párr.5 (mayo de 2013)

⁴ *Ibid.*, párr. 50.

⁵

⁶ Agenda de políticas públicas incluidas en el estudio: Bank Financing to Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Colombia, Constantinos Stephanou World Bank, Camila Rodríguez, affiliation not provided to SSRN, World Bank Policy Research Working Paper No. 4481, 1 de enero de 2008.

⁷ A/CN.9/727.

confined only to micro-business. As definitions of micro-business and small enterprise vary substantially by region and from country to country⁸, the same factors defining an enabling legal environment should pertain to both micro and small/medium-sized businesses⁹.”

En consecuencia es necesario crear un ambiente legal que permita establecer mecanismos de entrada a la formalización incluyendo aspectos cruciales como la creación simplificada de sociedades mercantiles, el acceso al crédito, la resolución de conflictos y la insolvencia simplificada, es decir un marco legal que tenga en cuenta todo el ciclo económico de la micro, pequeña y mediana empresa¹⁰.

III. Promoción de un desarrollo sostenible y el Estado de Derecho

La Declaración del Milenio de Naciones Unidas¹¹ referida al desarrollo y erradicación de la pobreza ha resaltado el potencial que tiene la iniciativa empresarial para contribuir a alcanzar objetivos concretos de desarrollo sostenible.

En la priorización del trabajo de la CNUDMI debe considerarse el impacto que la creación de este ambiente legal propicio para las Mipymes puede llegar a tener en un desarrollo inclusivo, sostenible y equitativo y en la promoción del Estado de Derecho (Rule of Law), tal y como quedó ampliamente demostrado en el Coloquio anteriormente citado.

El vínculo entre la creación de este ambiente legal propicio, la promoción del desarrollo y el Estado de Derecho también ha sido resaltado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como lo ratifica un informe reciente de la Secretaría¹²:

“The creation of an enabling legal environment also contributes to reinforcing the rule of law at country level which, as stressed by the General Assembly in its

⁸ “Lack of a clear definition is the main challenge in ensuring SME finance” see CGAP, Financial Access Report 2010, page 37, also including examples of various definitions of SMEs. A definition of SMEs and/or microbusiness can be found in the European Union Commission Recommendation of 6 May 2003 (2003/361/EC), in Microenterprise Results Reporting: Methodology and Statistical Annexes FY 2010 19, U.S.AID available at www.usaid.gov/our_work/economicgrowth_and_trade/mlcro/MRR_FY10_MethodologyStatistical_Annexes_82211_Final.pdf or. Different definitions of microcredit also exist, see for instance Basel Committee on Banking Supervision, Microfinance activities and the Core Principles for Effective Banking Supervision, August 2010, págs. 34-35.

⁹ Microfinance: creating an enabling legal environment for micro-business and small and medium-sized enterprises Note by the Secretariat, A/CN.9/780, párr. 12 (mayo de 2013).

¹⁰ En este mismo sentido el Banco Mundial afirma: “...There is a host of advantages brought about by the depth and importance of the SME sector. That also Implies that the SME sector must be taken into account when drafting legislation or designing a regulatory system for enterprises, including the crucial aspect of restructuring and liquidating distressed businesses” José M. Garrido en “Issues in the treatment of the insolvency of SMEs in Asia”, FAIR Kuala Lumpur 2011. pág. 3.

¹¹ Disponible en www.un.org.

¹² Citado en el Informe Microfinance: creating an enabling legal environment for micro-business and small and medium-sized enterprises Note by the Secretariat, A/CN.9/780, párr.13 (mayo de 2013).

Resolution on the Rule of Law¹³, is conducive to the growth of a fair, stable and predictable system for generating inclusive, sustainable, and equitable development. It is worth noting that most recently the General Assembly, once again “recognizing the important contribution entrepreneurship can make to sustainable development¹⁴”, has encouraged “governments to develop and implement policies ... that address the legal, social and regulatory barriers to equal and effective economic participation and promote entrepreneurship”. This appeal has also been extended to the international community which has been asked “to support the efforts of countries to promote entrepreneurship and foster the development of small and medium-sized enterprises and microenterprises¹⁵”.

El impacto en el Estado de Derecho es particularmente relevante en la regulación de las micro y pequeñas empresas, teniendo en cuenta que por lo menos la mitad de la fuerza laboral alrededor del mundo y la tercera parte de la economía mundial pertenece al sector informal.

En un país como Colombia no es fácil establecer cuántas micro y pequeñas empresas existen y están operando pues este sector se está desarrollando en gran medida dentro de la informalidad¹⁶.

Las empresas informales operan por fuera de la ley en ocasiones se ven envueltas en operaciones de crimen organizado¹⁷.

El informe presentado por la Secretaría enfatiza: “...The results, however, do not vary: microbusinesses cannot enforce contracts, get formal bank loans or expand beyond a very small local network^{18,19}. In sum, they have little option “but to trade in the informal economy²⁰” y se concluye: “...the informal sector perpetuates non-compliance with the law, increasing risks for loss of tax revenue, corruption, and a poor environment for investment. It will not naturally evolve into a formal sector, which allows businesses to grow, obtain credit on normal terms, increase employment and contribute to the tax base²¹.”

¹³ A/RES/67/97.

¹⁴ A/RES/67/202.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ “existing studies have estimated the size of the informal economy in Colombia between 35 and 44 percent of GDP, a figure that has apparently grown over the past decade” Cardenas y Mejia (marzo 2007) y Perry (mayo 2007) para tener una perspectiva de las causas y de las implicaciones de la informalidad. Citado en Bank Financing to Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Colombia, Constantinos Stephanou World Bank, Camila Rodriguez, affiliation not provided to SSRN, World Bank Policy Research Working Paper núm. 4481, 1 de enero de 2008.

¹⁷ Informe Microfinance: creating an enabling legal environment for micro-business and small and mediumsized enterprises Note by the Secretariat, A/CN.9/780, párr. 6 (mayo de 2013).

¹⁸ *Ibid.*, cita el “Report of the Commission on the Legal Empowerment of the Poor, Making the Law Work for Everyone, Volume 1, 2008, pág. 15.”

¹⁹ *Ibid. supra* 15.

²⁰ *Ibid. supra* 16, cita el mismo reporte pág. 39.

²¹ *Ibid. supra* 15 párr. 49.

3.1 La informalidad en Colombia

Un reciente estudio del Banco Mundial²² titulado “Informalidad: escape y exclusión” (Perry y otros, 2007) explica la naturaleza de la informalidad en Colombia como una función tanto de la “exclusión”²³ económica como del “escape”²⁴ hacia la informalidad de empresas del sistema formal²⁵.

La informalidad según el estudio es un síntoma de regulaciones inadecuadas que aumentan los costos y disminuyen los beneficios de la formalidad²⁶. Por lo tanto es imperativo pensar en la creación de un ambiente legal propicio para las micro, pequeñas y medianas empresas que acabe con la exclusión y que desestime el escape hacia la informalidad por parte de las empresas formalmente establecidas.

Durante los últimos años, el Gobierno de Colombia ha venido desarrollando importantes reformas en el propósito de lograr la promoción del desarrollo y del Estado de Derecho en diversas áreas del derecho comercial, en el entendido de que la regulación usada como un instrumento transversal de política permite mejorar las condiciones de acceso al mercado y al crédito, reduce los costos de transacción y mejora la competitividad de las empresas²⁷.

Dentro de las reformas relevantes adelantadas en este sentido en Colombia, se encuentran las relativas a la simplificación y flexibilización de trámites para registro y creación de sociedades mercantiles a través de la Ley 1258 de 2008 (Ley SAS); la Ley 1563 de 2012 sobre arbitraje nacional e internacional; que introduce el mecanismo de la resolución alternativa de conflictos por medios electrónicos para pequeñas causas; la Ley 1564 de 2012 en donde se establece el Régimen de Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante con procedimientos híbridos para resolver la insolvencia y el proyecto de reforma del Régimen de Garantías Nobiliarias que cursa actualmente en el Congreso de la República²⁸.

²² Contenido en el informe 42698 de 2010 Colombia, Informality in Colombia, Implications for Worker Welfare and Firm Productivity, Colombia and México Country Management Unit Human Development Department Latin America and the Caribbean Region, Banco Mundial, 1 de marzo de 2010, disponible en www.dnp.gov.co.

²³ “El concepto de “exclusión” refleja la manera en que la informalidad ha sido tradicionalmente vista en América Latina: que los trabajadores y empresas informales generalmente preferirían acceder a la categoría formal (inscribirse ante las autoridades, pagar impuestos, tener acceso a la seguridad social) pero no pueden hacerlo por razones vinculadas al estado de la economía, al funcionamiento del mercado laboral o al entorno regulatorio”.

²⁴ “El concepto de “escape”, por el contrario, plantea que algunos trabajadores y empresas son informales por una cuestión de elección. Esto significa que, luego de considerar los beneficios y costos de la formalidad, algunos trabajadores y empresas deciden salir del sector formal. Dados los beneficios y costos (reales o percibidos) y las oportunidades y restricciones existentes, dichos trabajadores y empresas de hecho prefieren la informalidad”.

²⁵ “Formalización Empresarial, la base de perdurabilidad para el desarrollo económico”, Luis Guillermo Vélez Cabrera, Revista Coyuntura Pyme, ANIF, Bogotá, abril 2013, Ed. 41.

²⁶ En este mismo sentido se puede establecer en el informe de la Secretaría: “Excessive regulation, too many laws and too many outdated laws, will discourage transition of business to the formal sector.” A/CN.9/780, párr. 49.

²⁷ *Ibid.*, *supra* nota 23.

²⁸ A/CN.9/780, párrs. 16, 24, 26 y 47 (mayo de 2013).

Estas reformas, de acuerdo con las estadísticas de 2009-2010, han fomentado el crecimiento y la formalización de las empresas en más del 25%²⁹.

IV. Promoción del Desarrollo y del Comercio Internacional

En la revisión que hiciera la Comisión respecto de la orientación estratégica para la CNUDMI y en lo que tiene que ver con la asignación de recursos, se planteó la necesidad de fijación de prioridades por parte de la Comisión³⁰. La decisión para la fijación de las prioridades en el trabajo de la CNUDMI, cuando existen propuestas enfrentadas, debe tomar en consideración no solo su actual y posible alcance, su pertinencia en el contexto del comercio y las relaciones comerciales³¹ sino también el impacto que el tema propuesto pueda tener en el desarrollo del comercio internacional³².

En el Coloquio no solo se enfatizó en la necesidad desde el punto de vista económico de la necesidad de creación de un ambiente legal propicio para las empresas sino también su efecto en el desarrollo del comercio internacional. El informe de la Secretaría concluyó:

“...It was stressed that work in establishing such an environment would be consistent with the Commission’s primary mandate to promote coordination and cooperation in the field of international trade, including regional cross-border trade. This was consistent also with the findings of the 2011 UNCITRAL Colloquium that microfinance had become a globally recognized form of cross border finance, that it kept growing world-wide, that legal, regulatory and market gaps kept the sector from operating as well as it should and that this had created a role for international legal standard-setting³³. Noting that cross-border recognition of these new and varied legislative issues and emerging structures was needed for MSMEs operating in regional markets in order to provide a recognizable international basis for transactions and avoid problems that can arise because of a lack of business recognition³⁴, participants further suggested that a flexible tool, such as a legislative guide or a model law according to the topics, would contribute to harmonizing efforts in this sector and provide momentum for reforms which would further encourage micro-business participation in the economy³⁵.”

En lo que tiene que ver con la constitución y registro simplificado de sociedades mercantiles, el informe de la Secretaría cita³⁶ a la Cámara de Comercio Internacional que ha sostenido que “...company law, where businesses are bound by

²⁹ *Ibid.*, párr. 16.

³⁰ A/DN.9/752/Add.1.

³¹ *Ibid.*, párr. 24.

³² A/CN.9/774, párr. 22.

³³ A/CN.9/727, párrs. 6 y 7.

³⁴ In this respect, contract law differs significantly from other fields of law, such as company law, where businesses are bound by the forms of legal entity created by the legislator, and the diversity of national forms of legal entity does indeed cause problems for SMEs. Véase, International Chamber of Commerce, ICC Position on the European Commission proposal for a regulation on a Common European Sales Law, julio de 2012, pág. 2, available at ICC Position on the European Commission proposal for a regulation on a Common European Sales Law

³⁵ A/CN.9/780, párr. 50.

³⁶ Véase cita *supra* 32.

the forms of legal entity created by the legislator, and the diversity of national forms of legal entity does indeed cause problems for SMEs.

Adicionalmente, el Banco Mundial ha encontrado que “...economies with modern business registration “grow faster”³⁷, “promote greater entrepreneurship and productivity”³⁸, “create jobs”³⁹, “boost legal certainty”⁴⁰ and “attract larger inflows of foreign direct investment”⁴¹”.

Una consideración fundamental en el desarrollo futuro del comercio internacional será la habilidad de las micro y pequeñas empresas de los países con economías en desarrollo o en transición para alcanzar los mercados internacionales, particularmente través del comercio electrónico. En el Informe de la Secretaría también se concluye que:

“...Internet usage increased by nearly 3000 per cent over the last 10 years, in the Middle East by nearly 2,250 per cent, in Latin America by over 1,200 per cent (for instance Brazil ranks fifth, Mexico twelfth and Colombia eighteenth in the world in number of individuals connected to the internet), and in Asia by nearly 800 per cent. Globally, Internet usage has increased by 528 per cent over the last decade: approximately one third of the world's population is now connected to the Internet. That number is expected to increase to 47 per cent by 2016⁴².”

Pero para que las micro y pequeñas empresas alcancen efectivamente el mercado global de comercio electrónico, será necesario desarrollar un ambiente legal propicio que promueva confianza en las transacciones de comercio electrónico transfronterizas y proporcione un sistema perdurable y continuo para el comercio.

V. Propuesta para el Desarrollo por iniciativa de un país con una economía en desarrollo o emergente (*A Bottom Up Approach*)

Debe tenerse en cuenta para efecto de tomar la decisión de priorizar la labor de la CNUDMI en la creación de un ambiente legal propicio para las Mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas) las propuestas realizadas por un país en vía de desarrollo y no solamente las provenientes de países altamente desarrollados. El Informe de la Secretaría explica que:

“...An improved legal infrastructure for MSMEs is needed which should rest on a global policy vision and not just isolated devices. Simply adapting traditional system laws to MSMEs will not work. Experience has shown that transposing laws from other, more highly-developed, jurisdictions is similarly unhelpful, since law needs to fit the culture and circumstances of the country. It will thus be important to prepare principles that are global in nature and can be tailored by countries according to their needs. UNCITRAL has proven to be well-placed as a forum for

³⁷ World Bank, IFC, Doing Business 2013, Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, pág. 21, citado en el informe de la Secretaría A/CN.9780 párr. 10.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, nota 16, pág. 25, citado en el informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 10.

⁴⁰ *Ibid.*, pág. 21, citado en el informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 10.

⁴¹ Informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 10.

⁴² Véase Internetworld Stats: Usage and Population Statistics, available at www.internetworldstats.com.

developing such general principles and legislation that is acceptable by a wide range of countries with different legal traditions. Therefore, the Commission could play a leading role in helping to create a level playing field by promoting best practices and sharing knowledge with countries seeking guidance in this area⁴³”.

VI. Elementos necesarios para la creación de un ambiente legal propicio

La CNUDMI, aprobó en su sesión plenaria 45° en 2012, el énfasis debía tener el Coloquio en Microfinanza y cuestiones conexas, en centrarse “en la facilitación de la constitución y el registro simplificados de empresas; el acceso al crédito para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas; la solución de controversias aplicable a operaciones microfinancieras; y otros temas relacionados con la creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y pequeñas y medianas empresas⁴⁴.”

De conformidad con esa decisión, en el Coloquio se concluyó que: “...a flexible tool, such as a legislative guide or a model law according to the topics, would contribute to harmonizing efforts in this sector and provide momentum for reforms which would further encourage micro-business participation in the economy⁴⁵.”

6.1 Facilitación de la constitución y el registro simplificados de empresas

El Coloquio concluyó que:

“...The starting point could be guidance that allows for simplified business start-up and operation procedures. In this regard, attention would be drawn to simplified corporate structures with easy establishment and minimal formalities, limited liability, flexible management and capitalization structure, plus ample freedom to contract. Considering the current absence of any internationally recognized standards or direction for countries wishing to adopt effective new forms, such a legal framework would significantly contribute to the formalization of thousands of enterprises that would otherwise remain in the informal sphere⁴⁶”.

El informe de la Secretaría contiene información relevante acerca de la experiencia colombiana en relación con la constitución y el registro simplificados de empresas⁴⁷.

⁴³ Informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 49.

⁴⁴ Informe de la Comisión, 45° sesión, UN Doc. A/67/17, párr. 49.

⁴⁵ Informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 50.

⁴⁶ F. Reyes, *Latin American Company Law — A New Policy Agenda: Reshaping the Closely-Held Entity Landscape*, 2013, page ii. Citado en el informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 51.

⁴⁷ “In Colombia, a major legal reform effort in the past 15 years has led to the development of a hybrid business form prioritizing flexibility, contractual freedom and limited liability: the so called sociedad por acciones simplificada (SAS). An SAS can be formed by one or more shareholders and can be incorporated via a relatively simple private or electronic document at minimal cost. The Simplified Stock Corporation Act (2008) relies on a system of ex post regulation in the form of enforceable standards during operation (as opposed to ex-ante regulation which creates rules to be met during establishment) to target abusive behavior, thus lowering costs for establishing micro businesses. In fact, compliance with strict requirements to set up a business, e.g. minimum legal capital or public deeds of incorporation, affects all

Además se hace mención de un estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades de Colombia que muestra el impacto de la simplificación y flexibilización en la incorporación de sociedades en Colombia, contenido en el “Anexo A” de este documento.

Estudios de la Comisión Europea⁴⁸ revelan que las diferencias en el derecho societario también pueden dificultar el comercio transfronterizo y limitar las operaciones internacionales: “...Currently on average only 93% of the EU companies involved in the sales of goods export inside of the EU⁴⁹. The majority of them (62% in B2B and 57% in B2C) export to no more than 3 other MS⁵⁰. One of the reasons for this relatively low level of cross-border trade - besides a lack of interest in export - is that some companies are hindered by regulator (e.g. differences in tax regulations, contract law, administrative requirements and company law) and practical barriers (e.g. language, transportation and after-sales maintenance). Recent business surveys show that the regulator barriers are a greater hindrance to the expansion of cross-border trade than the practical ones⁵¹.

6.2 Otros asuntos a tener en cuenta en la creación de un ambiente legal propicio

El Coloquio concluyó que había otros elementos esenciales para la creación de un ambiente legal propicio que tienen relevancia con el ciclo de vida de la empresa. Estos incluyen mecanismos de resolución de conflictos, transferencias electrónicas, pagos móviles, acceso al crédito e insolvencia.

6.2.1 Otros asuntos a tener en cuenta en la creación de un ambiente legal propicio

Se resaltaron las dificultades que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas en el acceso a la justicia y la necesidad de establecer sistemas adecuados de resolución de conflictos en la microfinanciación. En el informe contenido en el documento A/CN.9/756⁵², la Secretaría ya había presentado la situación de los mecanismos de resolución de controversias y el problema del acceso de los pobres a la justicia.

entrepreneurs. On the other hand, when standards that are enforceable ex post are used (e.g. abus de droit or equal treatment rules, that leave discretion for adjudicators to determine ex post whether violations have occurred), there is a cost only for those entrepreneurs who breach the standards. However, this approach requires effective judicial infrastructure to oversee and enforce ex-post standards. Since the SAS legislation was enacted in 2008 about 181,742 SASes (the data refers to November 2012) have been set-up, most of which, it is estimated, were pre-existing informal businesses. The SAS account for over 95 per cent of market share and, according to 2009-2010 data, they have enabled a growth in formalization of business entities of over 25 per cent.” Informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 16.

⁴⁸ European Commission, Brussels 11-10-2011, SEC (2011) 1165 Final, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law”. COM (2011) 635 final. pág. 10.

⁴⁹ Véase Annex on calculations of transaction and opportunity costs (Annex III).

⁵⁰ EB 320, págs. 55 y 321, pág. 56.

⁵¹ EB 320 and EB 321, the SME Panel and EBTP surveys. Similarly, a survey by Eurochambres in 2010 found that the differences in legislation were the main difficulty in cross-border trade for 36% of the respondents. It was conducted among 1,330 companies in 12 EU MS and Croatia. 83% of the respondents were involved in B2C transactions while 57% were delivering products cross-border.

⁵² Párr. 23 y siguientes.

“The Commission may thus wish to consider whether it would be appropriate to undertake preparation of notes⁵³ on how a system of dispute resolution in the field of microfinance should be organized. Such notes could be designed for use by legislators and administrators in considering whether a country has established a system that effectively serves the needs of MSMEs⁵⁴.

“Micro borrowers often lack knowledge of their rights and how to protect them⁵⁵. Furthermore, the formal justice system tend to exclude them “because they cannot afford the costs related to lawyers, or paying court fees....court procedures can be slow, and it is not uncommon for courts to have a large backlog of cases”⁵⁶. Yet, extrajudicial third-party dispute resolution mechanisms are rarely in place, thus limiting the effectiveness of any microfinance legal framework for client protection. As a result, four billion of the world’s population lack access to justice^{57,58}.

En su 44º periodo de sesiones, la Comisión⁵⁹ señaló que un marco legal y reglamentario propicio para la microfinanza incluía el establecimiento de procedimientos justos, eficientes, transparentes y baratos para resolver las controversias que surgieran a raíz de las operaciones de microfinanciación, y que la ausencia de esos procedimientos para los clientes de la microfinanza era una cuestión que debía examinarse más a fondo.

Tenemos entonces la oportunidad de examinar más a fondo este tema, con la propuesta de creación de un nuevo grupo de trabajo que asuma el conocimiento de esta temática.

6.2.2 Banca móvil y dinero electrónico

Los avances tecnológicos relativos a la banca móvil y el dinero electrónico hacen que estos tengan una importancia cada vez mayor como servicio financiero y como mecanismo de inclusión financiera⁶⁰, lo que hace necesario determinar para ellos directrices legislativas adecuadas⁶¹. Además se requiere de la definición de conceptos claves con un enfoque armonizado de la regulación de estas operaciones, equilibrando la necesidad de inclusión financiera con la necesidad de protección de la población de clientes vulnerables⁶².

⁵³ For instance, in the past the Commission prepared notes to assist arbitration practitioners during the course of arbitral proceedings, see *UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings* (1996).

⁵⁴ Informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 52.

⁵⁵ Véase A/CN.9/727.

⁵⁶ Véase A/CN.9/756, párr. 24.

⁵⁷ Véase *Report of the Commission on the Legal Empowerment of the Poor, Making the Law Work for Everyone*, vol. 1, 2008, pág. 13 y A/CN.9/756, párr. 24.

⁵⁸ Informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 8.

⁵⁹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo sexto período de sesiones. Suplemento núm. 17 (A/66/17)*, párrs. 242 y 246.

⁶⁰ Véase A/CN.9/756, IV Dinero Electrónico, pág. 18 y siguientes.

⁶¹ Unresolved legal issues surrounding the nature of e-money were already noted in the 2011 UNCITRAL Colloquium on Microfinance, together with their potential to negatively affect low income people. Véase A/CN.9/727, párrs. 43 y 44 citado en el informe de la Secretaría A/CN.9/780, párr. 9.

⁶² A/CN.9/756, párr. 54.

El Coloquio concluyó que: las transferencias electrónicas (incluidos los pagos mediante dispositivos móviles) ofrecían a las MYPIME que operaban en el sector no regulado de la economía la oportunidad de tener acceso efectivo a servicios financieros. Los instrumentos actuales de la CNUDMI relacionados con el comercio electrónico y las transferencias de crédito internacionales pueden adaptarse a los sistemas de pago con dispositivos móviles reconocidos en el Coloquio (véase el párr. 35 *supra*). No obstante, a fin de ampliar su alcance, se sugirió que ... sería particularmente importante ofrecer una definición clara de conceptos clave como el depósito, el pago y el dinero electrónico, así como orientación sobre la distribución de los riesgos entre los proveedores y los clientes⁶³.

6.2.3 Acceso al crédito

El acceso al crédito para la pequeña, la mediana y la microempresa, es uno de los temas de labor futura de la CNUDMI según lo decidido por la Comisión⁶⁴, la cual decidió que la transparencia en las operaciones de crédito no es un asunto de “regulación prudencial” sino un concepto relativo a los derechos de los clientes y su protección, asunto relevante para la ley comercial⁶⁵.

En el Coloquio se concluyó que “An enabling legal environment promoting access to credit for MSMEs would address commercial law matters arising in the context of secured and unsecured credit agreements. Guidance from the Commission, based on best practices, could deal with transparency in lending and enforcement in all kinds of lending transactions⁶⁶.”

6.2.4 Insolvencia para las micro, pequeñas y medianas empresas

En el Coloquio se resaltó la necesidad de establecer reglas para la insolvencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, por cuanto las reglas que existen no se ajustan adecuadamente al tamaño y a las necesidades de este sector empresarial. Lo anterior trae como efecto que las pequeñas empresas no obstante ser viables, no sobrevivan a una situación de insolvencia por la imposibilidad de llegar a acuerdos de refinanciación con sus acreedores.

Dadas las particulares características de las micro y pequeñas empresas, se requieren mecanismos de insolvencia alternativos, más expeditos, flexibles y menos costosos; distintos a los que tradicionalmente se han diseñado para la gran empresa⁶⁷.

En el Coloquio se recomendó la inclusión de la insolvencia en la esfera de trabajo de la CNUDMI, para mejorar la posibilidad de perdurabilidad de las micro y pequeñas empresas, de manera específica se estableció que: “...the Commission may wish to address the insolvency of MSMEs with the objective to ensure fast-track procedures and business rescue options so as to develop adequate and workable

⁶³ Informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 53.

⁶⁴ 44º período de sesiones de la Comisión (A/CN.9/727).

⁶⁵ Informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 36.

⁶⁶ Informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 54.

⁶⁷ Informe de la Secretaría A/CN.9/780 párrs.44 y 45.

alternatives to formal insolvency processes in line with both the key characteristics of an effective insolvency system and the needs of MSMEs^{68,69}.

VII. Conclusión

Como se ha demostrado a lo largo de esta propuesta, existe una urgente necesidad de iniciar una reflexión a nivel global acerca de la importancia de las microfinanzas y de otros asuntos relacionados con esta que deriven en la creación de un ambiente legal propicio para las micro, pequeñas y medianas empresas.

En ese propósito el Gobierno de Colombia propone a la Comisión de la CNUDMI dar el mandato necesario para establecer un nuevo grupo de trabajo que se centre en el ciclo de vida de la empresa, particularmente de las micro y pequeñas empresas que son los sujetos de la microfinanza; iniciando con la facilitación de la constitución y registro simplificado de sociedades mercantiles y de otros asuntos, como los mencionados anteriormente, relacionados y necesarios para el establecimiento de un ambiente legal propicio para este tipo de actividades mercantiles.

El Gobierno de Colombia espera con atención que la discusión sobre este asunto se pueda realizar en la próxima sesión de la Comisión.

Anexo A

En Colombia, la Superintendencia de Sociedades ha hecho una aproximación al efecto combinado en los procesos de formalización empresarial de dos leyes, la Ley 1258 de 2008 (Ley de SAS) y la Ley 1429 de 2010 (Ley de Primer Empleo). Las dos normas citadas son parte de la política de flexibilización y simplificación de trámites⁷⁰.

El índice de medición de formalización utilizado en este análisis es el de la medición del número de microempresas que no tienen registro mercantil sobre el universo total de microempresas.

La Superintendencia comparó el número de sociedades activas entre abril del 2010 y enero del 2013, según información del RUE (Registro Único Empresarial de Colombia), para ver cuál podría ser el efecto combinado a partir del 2010 de las dos leyes que confluyen en ese momento.

* Tabla 1

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) fue la única que permitió un aumento en el registro de nuevas sociedades mientras que las otras modalidades asociativas disminuyeron.

⁶⁸ A. Idigbe, O. Kalu, *Best practice and tailored reforms in African insolvency: lessons from JNSOL*, December 2012, pág. 2.

⁶⁹ Citado en el Informe de la Secretaría A/CN.9/780 párr. 55.

⁷⁰ Formalización Empresarial, la base de la perdurabilidad para el desarrollo económico”, Luis Guillermo Vélez Cabrera, *Revista Coyuntura Pyme*, ANIF, Bogotá, Abril 2013, Ed. 41 pág. 41.

* Tabla 2

En un análisis más detallado por tamaño de empresa para entender de dónde vienen las 192.602 sociedades SAS que aparecen activas en enero del 2013 vemos como las sociedades que se registraron como SAS totalmente nuevas, es decir que no eran SAS en el 2010 y que no provenían de una estructura societaria ya existente, suma 132,873 sociedades y su concentración se encuentra en el mundo de las micro y pequeñas empresas (92% del total de la nuevas SAS). El efecto de incremento del número de sociedad que realizaron su registro mercantil bajo una figura más flexible, es solo un ejemplo del posible impacto que en la formalización pueden tener marcos normativos más acordes a la realidad de las MiPyMes (Micro, pequeñas y medianas empresas).

Tabla 1*
Sociedades activas a cortes Abril de 2010 y Enero del 2013

	<i>Empresas asociativas de trabajo</i>	<i>Empresas unipersonales</i>	<i>Otras sociedades</i>	<i>Sociedad agraria de transformación</i>	<i>Sociedad anónima</i>	<i>Sociedad colectiva</i>	<i>Sociedad en comandita</i>	<i>Sociedad extrajera</i>	<i>Sociedad limitada</i>	<i>Por acciones simplificadas</i>	<i>Total sociedades</i>
Corte enero 2013	12.574	55.182	8.030	31	41.724	289	27.249	2.564	320.760	192.602	661.005
Corte abril 2010	22.120	103.474	4.795	117	74.629	864	44.619	3.326	616.117	54.508	924.569
Diferencia entre 2013 y 2010	(9.546)	(48.292)	3.235	(86)	(32.905)	(575)	(17.370)	(762)	(295.357)	138.094	(263.564)

*Datos tomados del RUE.

Tabla 2*
Sociedades SAS en el 2013 y su procedencia

<i>Procedencias de las SAS en el 2013</i>	<i>Tamaño</i>				<i>Total general</i>
	<i>Gran Empresa</i>	<i>Mediana empresa</i>	<i>Microempresa</i>	<i>Pequeña empresa</i>	
Provenientes de otro tipo societario	904	3.386	15.803	10.127	30.220
Ya conformadas como SAS en el 2010	337	1.442	22.365	5.365	29.509
Nuevas sociedades creadas como SAS	266	1.161	122.655	8.791	132.878
Total general	1.507	5.989	160.823	24.283	192.602

*Datos tomados del RUE.

VIII. JURISPRUDENCIA RELATIVA A LOS TEXTOS DE LA CNUDMI (CLOUT)

La secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sigue publicando sentencias judiciales y laudos arbitrales pertinentes para la interpretación o aplicación de los textos derivados de su labor. Véase la descripción del sistema CLOUT (Jurisprudencia relativa a los textos de la CNUDMI) en la guía del usuario (A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.2), publicada en 2000 y cargada en Internet en el sitio www.uncitral.org.

El documento A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS puede obtenerse de la secretaría de la CNUDMI solicitándolo en la siguiente dirección:

UNCITRAL secretariat
P.O. Box 500
Vienna International Centre
A-1400 Vienna
Austria

Teléfono: (+43-1) 26060-4060 o 4061

Fax: (+43-1) 26060-5813

Correo electrónico: uncitral@uncitral.org

También puede consultarse en la página de la CNUDMI en Internet: www.uncitral.org.

Se pueden obtener de la secretaría ejemplares, en el idioma original, de los textos completos de las sentencias judiciales y laudos arbitrales sobre los que se haya informado en el contexto del CLOUT.

IX. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REFORMA JURÍDICA

Nota de la Secretaría sobre cooperación y asistencia técnica

(A/CN.9/775)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-7
II. Actividades de cooperación y asistencia técnicas	8-50
A. Planteamientos generales	8-18
B. Actividades concretas	19-50
III. Actividades del Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico	51-70
IV. Difusión de información	71-88
A. Sitio de la CNUDMI en Internet	72-74
B. Biblioteca	75-79
C. Publicaciones	80-83
D. Comunicados de prensa	84-85
E. Consultas generales	86
F. Sesiones de información para las misiones permanentes acreditadas en Viena	87
G. Conferencias informativas en Viena	88
V. Recursos y financiación	89-100
A. Fondo Fiduciario para Simposios de la CNUDMI	91-95
B. Fondo Fiduciario de la CNUDMI destinado a conceder asistencia para gastos de viaje a los países en desarrollo que la integran	96-100

I. Introducción

1. Las actividades de cooperación y asistencia técnicas encaminadas a promover la utilización y la adopción de sus textos son una de las prioridades de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), de conformidad con una decisión adoptada en su 20º período de sesiones (1987)¹.

2. En su resolución 67/89, de 14 de enero de 2013, la Asamblea General reafirmó la importancia que revestía, especialmente para los países en desarrollo y los países de economía en transición, la labor de cooperación y asistencia técnicas de la

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/42/17), párr. 335.*

Comisión y reiteró su llamamiento a los órganos responsables de la asistencia para el desarrollo, así como a los gobiernos en el marco de sus programas de asistencia bilateral, para que prestaran apoyo al programa de cooperación y asistencia técnicas de la Comisión y cooperaran y coordinaran sus actividades con ella.

3. La Asamblea General acogió con beneplácito las iniciativas tomadas por la Comisión para ampliar, por conducto de su Secretaría, su programa de cooperación y asistencia técnicas y observó con interés el enfoque global de esas actividades, basado en el marco estratégico para la asistencia técnica propuesto por la Secretaría con el fin de promover la adopción universal de los textos de la Comisión y difundir información sobre los textos de reciente aprobación.

4. Asimismo, la Asamblea General destacó la importancia de promover la utilización de los textos dimanantes de la labor de la Comisión para la armonización y unificación a nivel mundial del derecho mercantil internacional y, a tal fin, instó a los Estados que aún no lo hubieran hecho a que consideraran la posibilidad de firmar o ratificar esos instrumentos o de adherirse a ellos, incorporar las leyes modelo al derecho interno y alentar el uso de otros textos pertinentes.

5. En el sitio de la CNUDMI en Internet se publica con regularidad una relación actualizada del estado de la aprobación de los textos de la Comisión. También se la compila anualmente en una nota de la Secretaría titulada “Situación actual de las convenciones y leyes modelo” (véase en el documento A/CN.9/773 la compilación correspondiente al 46º período de sesiones de la Comisión).

6. En la presente nota se reseñan las actividades de cooperación y asistencia técnicas realizadas por la Secretaría desde la fecha de la nota anterior, que se presentó a la Comisión en su 45º período de sesiones, celebrado en 2012 (A/CN.9/753, de 26 de abril de 2012), y se informa sobre la obtención de recursos destinados a apoyar dichas actividades.

7. En otro documento (A/CN.9/776) se ofrece información sobre las actividades que actualmente llevan a cabo las organizaciones internacionales para armonizar y unificar el derecho mercantil internacional y sobre el papel que desempeña la CNUDMI en la coordinación de esas actividades.

II. Actividades de cooperación y asistencia técnicas

A. Planteamientos generales

8. Las actividades de cooperación y asistencia técnicas emprendidas por la Secretaría tienen por objeto promover la aprobación y la interpretación uniforme de los textos legislativos de la CNUDMI. Entre esas actividades figuran la prestación de asesoramiento a aquellos Estados que estudian la posibilidad de firmar o ratificar los instrumentos de la CNUDMI, o de adherirse a ellos, así como a los que estudian la posibilidad de adoptar alguna de sus leyes modelo o utilizar alguna de sus guías legislativas.

9. La labor de cooperación y asistencia técnicas puede consistir en: llevar a cabo misiones informativas y participar en seminarios y conferencias organizados en los planos regional o nacional; prestar asistencia a los países en el estudio de sus necesidades en materia de reforma legislativa, incluso mediante la revisión de su

legislación vigente; prestar asistencia en la preparación de normas jurídicas por las que se incorporen al derecho interno los textos de la CNUDMI; ayudar a los organismos de desarrollo, tanto multilaterales como bilaterales, a valerse de los textos de la CNUDMI en sus actividades y proyectos de reforma legislativa; prestar asesoramiento y asistencia a organizaciones internacionales y de otra índole, como asociaciones profesionales, colegios de abogados, cámaras de comercio y centros de arbitraje, en materia de aplicación de los textos de la CNUDMI; y organizar actividades de capacitación para facilitar la aplicación e interpretación de las normas jurídicas basadas en los textos de la CNUDMI por parte de magistrados y juristas.

10. A continuación se describen algunas de las actividades llevadas a cabo en el período que se examina. Las actividades marcadas con un asterisco se financiaron con cargo al Fondo Fiduciario para Simposios de la CNUDMI.

Iniciativas para un enfoque regional

11. La Secretaría siguió participando en el proyecto del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico relativo a la facilidad para efectuar operaciones comerciales (hacer valer los contratos), en coordinación con el Ministerio de Justicia de la República de Corea. Ese proyecto tiene como objetivo fortalecer el marco legislativo e institucional para asegurar el cumplimiento de los contratos en las economías del Foro y las economías adyacentes (Filipinas y Tailandia en 2012, Indonesia y el Perú en 2011*). En la segunda Conferencia sobre Medidas para Hacer Valer los Contratos (Seúl, 7 de noviembre de 2012*), se presentaron recomendaciones sobre la manera de mejorar el entorno jurídico para hacer valer los contratos en Tailandia y Filipinas. En 2013, el proyecto centrará su atención en Brunei Darussalam (que ocupa el 158º lugar entre 185 países), la Arabia Saudita (124º) y Viet Nam (44º), y se sugerirá que se adopten los textos de la Comisión sobre arbitraje, compraventa de mercaderías y comunicaciones electrónicas como posibles medidas de reforma legislativa en esos Estados (Arabia Saudita, 6 a 8 de mayo de 2013; Brunei Darussalam y Viet Nam, previsto para fines de mayo o comienzos de junio*). La participación de la Secretaría en el proyecto ha sido posible gracias a las contribuciones voluntarias recibidas del Gobierno de la República de Corea.

12. Entre otras iniciativas regionales en las que participa la Secretaría cabe citar la asociación con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)). La Secretaría asistió a una reunión en la que se examinaron proyectos futuros en la región de los Balcanes y las actividades ejecutadas hasta la fecha en el contexto del Fondo Regional Abierto para Europa Sudoriental al servicio de la reforma legal y para determinar zonas amplias de intervención para una posible tercera fase del programa. Las fases primera y segunda se centraron concretamente en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CIM) y en los mecanismos alternativos de solución de controversias, respectivamente (Belgrado, 14 a 16 de junio de 2012).

13. En la conferencia regional sobre el Oriente Medio, organizada por el proyecto de protección de la Facultad de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y por la Universidad Árabe de Beirut (Beirut, 9 a 11 de septiembre de 2012*), con el objeto de promover los textos de la Comisión en la

región árabe, la Secretaría presentó una ponencia sobre las actividades de la Comisión encaminadas a la armonización del derecho.

Promoción de la adopción universal de los instrumentos de derecho mercantil fundamentales

14. A ese respecto, un enfoque consiste en promover principalmente la adopción de los instrumentos de derecho mercantil fundamentales, es decir, aquellos tratados que ya gozan de una amplia adhesión, por lo que parecería especialmente conveniente lograr su adopción universal.

15. Los tratados que se consideran actualmente con arreglo a ese enfoque son la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras² (la Convención de Nueva York, una convención de las Naciones Unidas aprobada con anterioridad al establecimiento de la Comisión, pero que esta promueve activamente), cuya adopción universal ya ha pedido explícitamente la Asamblea General³, y la CIM.

Promoción general de la labor de la CNUDMI

16. Funcionarios de la Secretaría participaron en las actividades siguientes:

a) Representaron a la Comisión y presentaron una ponencia en una reunión de alto nivel, el Foro Centroamericano de Derecho y Derecho Internacional Privado, por invitación de la Corte Centroamericana de Justicia (Ciudad de Panamá, 30 y 31 de enero de 2013); y

b) Presentaron la labor de la Comisión e intercambiaron opiniones con los miembros de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (Bruselas, 21 de marzo de 2013).

Promoción de tratados aprobados recientemente

17. La Secretaría sigue promoviendo, incluso en el plano regional, los instrumentos de reciente aprobación a fin de alentar su firma y adopción por los Estados con miras a facilitar su pronta entrada en vigor.

18. La Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (la “Convención sobre las comunicaciones electrónicas”) entró en vigor el 1 de marzo de 2013. La Secretaría ha seguido promoviendo activamente su adopción, especialmente en la región de Asia y el Pacífico (en los párrafos 63 a 65 se describen las actividades pertinentes realizadas en esa región).

B. Actividades concretas

Compraventa de mercaderías

19. La Secretaría ha seguido alentando la adopción universal de la CIM. Con tal fin, se han celebrado cursos prácticos y conferencias, así como reuniones bilaterales

² Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 330, núm. 4739.

³ Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 62/65, de 8 de enero de 2008, párr. 3.

y otras formas de interacción. Respecto de la adhesión por el Brasil en marzo de 2013, la Secretaría participó en los últimos años en distintas actividades conexas (Río de Janeiro, 23 a 30 de junio de 2009⁴, San Pablo, 29 y 30 de abril de 2010⁵, y San Pablo, 3 y 4 de noviembre de 2011⁶).

20. La Secretaría ha seguido prestando apoyo a los Estados en el proceso de revisión de las declaraciones que formularon cuando pasaron a ser parte de la CIM, con miras a que las reconsideraren, si procede, a fin de seguir armonizando el alcance de la aplicación de la Convención.

21. Además, la Secretaría sigue promoviendo activamente la interpretación uniforme de la CIM, tanto mediante actividades relacionadas con la jurisprudencia relativa a los textos de la CNUDMI (sistema CLOUT)⁷ como mediante la prestación de capacitación especializada para magistrados, juristas y estudiantes, por ejemplo, el curso práctico sobre la CIM organizado para la Academia Judicial de la República Checa (Brno (República Checa), 14 de junio de 2012*) y el seminario celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena (Viena, 15 de octubre a 7 de noviembre de 2012).

22. Por último, la Secretaría ha seguido promoviendo la adopción y la interpretación uniforme de la Convención de las Naciones Unidas sobre prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías (Nueva York, 1974), enmendada por el Protocolo de 11 de abril de 1980 (Viena) (la “Convención sobre la prescripción”⁸), incluso invitando a los Estados que son partes en la versión no enmendada a considerar la posibilidad de adoptar la versión enmendada de la Convención sobre la prescripción.

Solución de controversias

23. La Secretaría ha elaborado instrumentos encaminados a proporcionar información sobre la aplicación e interpretación de los textos de la Comisión en la esfera de la solución de controversias. La Secretaría también ha participado en actividades de capacitación, en la promoción de instrumentos relativos al arbitraje y la conciliación y en la prestación de apoyo a la labor legislativa en curso. Habida cuenta de la alta tasa de adopción de esos textos, la demanda de asistencia técnica en la esfera de la solución de controversias sigue siendo particularmente aguda.

i) Elaboración de instrumentos para proporcionar información sobre la aplicación e interpretación de los textos de la Comisión en la esfera de la solución de controversias

24. Respecto de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (1958), se ha creado un sitio web (www.newyorkconvention1958.org) para poner a disposición del público la información reunida en la preparación de la guía de la Comisión sobre la Convención de Nueva York; en el 58º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) (Nueva York, 4 a 8 de febrero de 2013) se presentó una versión actualizada del sitio web (véase A/CN.9/765, párrs. 95 a 98).

⁴ A/CN.9/695, párr. 12 b).

⁵ A/CN.9/724, párr. 52.

⁶ A/CN.9/753, párr. 21.

⁷ Para más información, véase A/CN.9/777.

⁸ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1511, núm. 26119, pág. 3, y núm. 26121, pág. 99.

25. En cuanto a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985, enmendada en 2006), la Secretaría fue uno de los organizadores de las actividades siguientes relacionadas con el Compendio de Jurisprudencia sobre la Ley Modelo de 2012 (el “Compendio”): los días 8 a 10 de junio de 2012*, una ceremonia de presentación en Singapur, organizada junto con el Ministerio de Justicia de Singapur; y el 1 de marzo de 2013, una conferencia en Berlín, en colaboración con el Ministerio de Justicia y el Instituto Alemán de Arbitraje (DIS).

ii) *Apoyo a la labor legislativa y las actividades de capacitación en curso*

26. La Secretaría ha formulado observaciones respecto de lo siguiente:

a) proyectos de legislación sobre arbitraje, entre otros, para los Gobiernos de Eslovaquia, las Islas Cook, Palestina y Qatar;

b) proyectos de legislación sobre mediación, entre otros, para el Gobierno de Egipto; y

c) proyectos de normas de arbitraje de las instituciones arbitrales, entre otros, a solicitud de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), sobre los reglamentos de arbitraje de 1976 y 2010, de, las normas para el nombramiento de autoridades arbitrales de 1976 y 2010 y los servicios administrativos especiales de la SCC.

27. La Secretaría prestó asistencia técnica en apoyo de la creación de un centro de arbitraje mercantil en Ramallah (Ramallah (Estado de Palestina), 14 a 16 de diciembre de 2012).

28. La Secretaría también contribuyó, en el marco del proyecto de independencia judicial y empoderamiento jurídico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a la preparación de actividades de capacitación judicial para la Escuela Superior de Justicia de Georgia, a fin de capacitar a los magistrados de ese país en la esfera del arbitraje mercantil internacional.

29. El Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico organizó, junto con el Ministerio de Justicia y la Junta de Arbitraje Mercantil de la República de Corea, una conferencia sobre las perspectivas de Asia y el Pacífico respecto del arbitraje mercantil internacional (Seúl, 22 y 23 de noviembre de 2012; véase el párr. 58*).

30. La Secretaría organizó, junto con el Centro Internacional de Arbitraje de Viena de la Cámara Económica Federal de Austria y los Jóvenes Especialistas en Arbitraje de Austria, la Conferencia anual conjunta de arbitraje (Viena, 21 y 22 de marzo de 2013).

31. Entre otras actividades relacionadas con el arbitraje internacional que contaron con la participación o contribución de la Secretaría cabe mencionar las siguientes:

a) un seminario sobre la función de las Naciones Unidas en el arbitraje internacional, por invitación de la Academia Internacional de Arbitraje (París, 16 de julio de 2012);

b) un seminario acogido por el Chartered Institute of Arbitrators, en el que se presentó una ponencia sobre “La función de la CNUDMI en la solución de controversias, en su condición de promotora de la Convención de Nueva York y otros estándares jurídicos” (Londres, 6 de septiembre de 2012);

- c) una sesión plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón, en relación con la ejecución de los laudos arbitrales con arreglo a la Convención de Nueva York (Interlaken (Suiza), 9 de octubre de 2012);
- d) el tercer Foro Económico y Financiero para el Mediterráneo, que incluyó una sesión sobre conciliación y arbitraje, organizada por la Cámara de Comercio de Milán (Milán (Italia), 12 y 13 de noviembre de 2012);
- e) un curso práctico organizado por la Universidad Internacional MITSO (Belarús), en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Belarús, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la CNUDMI y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) sobre el tema de la solución de controversias relacionadas con las inversiones (Minsk, 19 y 20 de noviembre de 2012);
- f) una conferencia titulada “La función de los tribunales estatales en el arbitraje”, organizada por el Centro Regional de El Cairo para el Arbitraje Mercantil Internacional, en la que se presentaron instrumentos de asistencia técnica, como el Compendio de Jurisprudencia sobre la Ley Modelo de Arbitraje y el proyecto de guía de la Convención de Nueva York, con el objetivo, entre otros, de asistir a los magistrados en la interpretación y aplicación de la Ley Modelo y la Convención de Nueva York (Sharm El Sheikh (Egipto), 27 y 28 de noviembre de 2012);
- g) la 20ª Conferencia Anual sobre Arbitraje de Croacia, en torno al tema del arbitraje en las inversiones en Europa central y oriental (Zagreb, 5 a 7 de diciembre de 2012);
- h) la Conferencia Internacional de Arbitraje de Mauricio, en donde se presentó la labor de la Comisión y de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas en la promoción del estado de derecho y la función de las Naciones Unidas en la solución de controversias internacionales (Mauricio, 10 y 11 de diciembre de 2012); y
- i) un curso práctico sobre la armonización del derecho mercantil en la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), incluso en la esfera de la solución de controversias (Singapur, 11 y 12 de marzo de 2013; véase el párr. 59).

Comercio electrónico

32. La Secretaría ha seguido promoviendo la adopción de los textos de la CNUDMI sobre comercio electrónico, en particular en cooperación con otras organizaciones y haciendo hincapié en un enfoque regional (véanse los párrs. 10 y 63 a 65 del documento A/CN.9/776). También ha formulado observaciones sobre proyectos de legislación regional y nacional, por ejemplo, un proyecto de ley sobre comunicaciones y transacciones electrónicas preparado por el Gobierno de Botswana.

33. A resultas de esas actividades de promoción, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales entró en vigor el 1 de marzo de 2013 con Honduras, la República Dominicana y Singapur como Estados parte. Además, se promulgaron varias leyes nacionales sobre comercio electrónico y firma electrónica (véase A/CN.9/773).

34. La Secretaría también celebró consultas oficiosas con legisladores y funcionarios encargados de formular políticas de distintas jurisdicciones, entre ellas Sudáfrica y Viet Nam.

Contratación pública

35. De conformidad con las solicitudes hechas por la Comisión y el Grupo de Trabajo I (Contratación Pública), la Secretaría ha establecido vínculos con otras organizaciones internacionales que participan en la reforma de la contratación pública, con miras a fomentar la cooperación respecto de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública (la “Ley Modelo”) y su Guía para la incorporación al derecho interno (2012)⁹.

36. El objetivo de ese tipo de cooperación es asegurar que las exigencias y circunstancias regionales sean comprendidas por los gobiernos encargados de la reforma y que se informe a las organizaciones de las consideraciones normativas en que se basan esos textos, a fin de promover una comprensión cabal y un uso adecuado de la Ley Modelo en los planos regional y nacional¹⁰. La Secretaría aplica a esa cooperación un enfoque regional, y se prevé la realización de actividades con los bancos multilaterales de desarrollo de distintas regiones, centrando la atención en la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción (ámbitos en los que la reforma de la contratación pública desempeña una función crucial).

37. Con ese fin, la Secretaría ha participado como orador o presentador en una amplia variedad de reuniones internacionales, entre ellas las siguientes:

a) Participación como orador en el octavo Foro Regional sobre la Contratación Pública, acogido por el Gobierno de Albania, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD) y el Banco Mundial, al que asistieron funcionarios de Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kirguistán, Kosovo, la ex República Yugoslava de Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, y representantes de las organizaciones anfitrionas. Se examinaron temas como la contratación pública electrónica y los acuerdos marco con arreglo a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública (2011), en el contexto de la armonización de los regímenes internacionales y regionales de contratación pública (Tirana, 22 a 25 de mayo de 2012);

b) Participación continua en la iniciativa del BERD y la CNUDMI, en asociación con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), para el mejoramiento de la normativa sobre contratación pública en los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Mongolia¹¹. En el marco de esa iniciativa, durante el período que se examina se celebró en Bakú, los días 31 de mayo y 1 de junio de 2012*, un curso práctico sobre políticas de la contratación pública para el Gobierno de Azerbaiyán; en Viena, del 6 al 8 de marzo 2013, una reunión de examen del proyecto de ley sobre contratación pública

⁹ Se puede consultar en

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2012Guide.html.

¹⁰ Véanse los documentos A/CN.9/575, párrs. 52 y 67, A/CN.9/615, párr. 14, y A/66/17, párrs. 186 a 189.

¹¹ <http://www.ppi-ebrd-uncitral.com/index.php/en/the-initiative>.

para el Gobierno de Kirguistán; y en Viena, del 9 al 11 abril 2013, un curso práctico sobre contratación pública para el Gobierno de Tayikistán. Se trató el tema del uso de la Ley Modelo y la Guía para la incorporación al derecho interno para actualizar y modernizar las leyes y prácticas de contratación pública en la región. Con arreglo a esa misma iniciativa se realizó un análisis de diagnóstico de las leyes sobre contratación pública de Azerbaiyán, Federación de Rusia, Kirguistán y Mongolia, a fin de verificar si se ajustaban a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública;

c) Participación como orador en la VIII Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas, organizada por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), el Gobierno de Panamá y PanamaCompra, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo/Instituto para la Conectividad en las Américas (CIID/ICA). En la conferencia se examinaron las actividades realizadas por los países en pro de la reforma de la contratación pública y la ejecución y el mejoramiento del desempeño en esa esfera; se presentó la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública (2011) en el contexto de los estándares internacionales y la reforma de las contratación pública (Ciudad de Panamá, 11 a 13 de septiembre de 2012*);

d) Participación en un curso práctico organizado por el Banco Mundial, en cooperación con el BAD y el BERD, en donde presentó una ponencia sobre las prácticas internacionales de contratación pública, prestando especial atención a la Ley Modelo y la Guía para la incorporación al derecho interno, el alcance de las actividades de la Comisión y la importancia de las asociaciones con otros donantes a fin de velar por la coherencia y uniformidad de las reformas (Dushanbe, 7 a 9 de octubre de 2012*);

e) Prestación de cooperación y apoyo técnicos a la Subdivisión de Corrupción y Delitos Económicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en particular en la coordinación de la aplicación del artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en lo referente a la contratación pública, y prestando apoyo al proyecto de la UNODC titulado “Alianza entre el sector público y el privado para la probidad en la contratación pública”, como se señaló en la cuarta Conferencia de los Estados Parte en la Convención (Marrakech, (Marruecos) 24 a 28 de octubre de 2012). Entre esas actividades se incluyó la prestación de asesoramiento a los Gobiernos de la India y México sobre la reforma de sus marcos jurídicos y normativos de la contratación pública y la participación en reuniones de grupos de expertos y de otro tipo (24 a 26 de septiembre de 2012);

f) Participación como orador en una conferencia de la Red de Contratación Pública sobre la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública (2011) y la posible labor futura en las alianzas entre el sector público y el sector privado (Estocolmo, 3 y 4 de diciembre de 2012);

g) Celebración de un seminario en el BERD, en virtud de la iniciativa del BERD y la CNUDMI, para explicar los principios de la Ley Modelo y su uso con otros textos internacionales y regionales sobre contratación pública a fin de seguir armonizando su aplicación (Londres, 11 de enero de 2013*);

h) Participación en la conferencia Thomson Reuters sobre “Contratación pública: novedades del año último”, que se convoca para ofrecer información técnica a los especialistas locales e internacionales, funcionarios encargados de formular políticas y académicos sobre las novedades del año último relacionadas con la contratación pública. La sesión se tituló “Diálogo transatlántico” e incluyó debates sobre sistemas de cumplimiento institucional, criterios comparativos para las sanciones y la inhabilitación, propuestas de directrices de la Unión Europea sobre contratación pública y estrategias de armonización (Washington, D. C., 19 de febrero de 2013);

i) Participación como orador en la conferencia regional del BAFD-BERD sobre contratación pública, en la sesión sobre “Nuevas ideas de reforma: la Ley Modelo de la CNUDMI y el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio”. El propósito principal de la conferencia es servir de foro para reflexionar sobre el estado en que se encuentran los marcos jurídicos de la contratación pública en la región del Oriente Medio y África del Norte (Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez) y alentar sus actividades en curso y futuras de reforma del marco normativo (Marrakech (Marruecos), 22 a 24 de abril de 2013*); y

j) Participación en la Mesa Redonda sobre Liderazgo en la Contratación Pública en los Estados Unidos y Europa: cuestiones fundamentales para la reforma futura de la legislación sobre contratación pública, acogida por la Universidad del Ruhr, Bochum (Alemania) y la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington (Washington, D. C.), en cooperación con la Sección de Derecho de la Contratación Pública de la American Bar Association, la Asociación de Abogados Especialistas en Contratación Pública del Reino Unido y el Forum Vergabe e.V., y el Deutscher Anwaltverein, sobre nuevas cuestiones con respecto a la contratación pública en los Estados Unidos y Europa, la Ley Modelo de la CNUDMI y el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, centrando la atención en el mejoramiento de la cooperación transatlántica en la lucha contra la corrupción, las actividades de cumplimiento, las impugnaciones de licitaciones, las fusiones y adquisiciones, el control de las exportaciones, cuestiones académicas e iniciativas de los colegios de abogados (Viena, 19 de febrero de 2013).

Prestación de apoyo a la labor legislativa y las actividades de capacitación en curso

38. La Secretaría también ha prestado asesoramiento continuo a los Gobiernos de Jamaica y Trinidad y Tabago (con el apoyo del BID) respecto de la reforma de sus marcos jurídicos y normativos de la contratación pública.

39. Presentó una ponencia sobre la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública y su Guía para la incorporación al derecho interno (2011 y 2012) dirigida a estudiantes de derecho y política de contratación pública internacional de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) y a estudiantes del programa de maestría Tor Vergata sobre contratación pública del BERD-Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia (MAE)-Organismo de Contratación Pública de la India (CONSIP), con miras a alentar una mayor comprensión de las disposiciones de la Ley Modelo y su uso como instrumento en la reforma de la contratación pública (Nottingham (Reino Unido), 14 y 15 de enero de 2012, y Roma, 11 y 12 de abril de 2013);

40. Presentó una ponencia sobre la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública y la Guía para la incorporación al derecho interno (2011 y 2012) dirigida a estudiantes de contratación pública para el desarrollo sostenible, en el Centro de Comercio Internacional (CCI) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Universidad de Turín, una vez más para alentar una mayor comprensión de las disposiciones de la Ley Modelo y su uso como instrumento en la reforma de la contratación pública (Turín (Italia), 29 de febrero y 1 de marzo de 2012); y

41. Celebró una sesión de capacitación sobre la CNUDMI para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), organizada y financiada por el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y con la participación de la Organización Internacional de Derecho del Desarrollo. Entre otros temas, se examinaron la contratación pública y el fomento de la infraestructura, el arbitraje y la conciliación comercial internacional, la solución de controversias en línea, el transporte internacional de mercaderías y un resumen general de otras esferas comprendidas en el mandato de la CNUDMI (Roma, 21 a 23 de mayo de 2012).

Insolvencia

42. La Secretaría ha promovido la utilización y adopción de textos sobre la insolvencia, en particular la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza y la Guía legislativa sobre el régimen de la insolvencia, mediante su participación en diversos foros internacionales. Entre esas actividades figuran las siguientes:

a) Presentación, en la conferencia de políticas titulada “Reestructuración financiera y legislación de quiebra”, de una ponencia sobre prácticas regionales y mundiales de reestructuración financiera y legislación de quiebra: lecciones para los Emiratos Árabes Unidos/Dubai. El propósito de la conferencia fue examinar las mejores prácticas, a nivel tanto regional como internacional, sobre la base de la legislación del Reino Unido, los Estados Unidos y Singapur y haciendo hincapié en varias cuestiones fundamentales relativas a la insolvencia en el contexto de un nuevo proyecto de ley de la insolvencia para Dubai y los Emiratos Árabes Unidos (Dubai (Emiratos Árabes Unidos), 13 a 16 de mayo de 2012*);

b) Organización de un curso práctico sobre la labor de la CNUDMI relativa a la legislación sobre insolvencia en la conferencia celebrada con motivo del 50º aniversario de la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados (AIJA), a fin de crear conciencia sobre la labor de la CNUDMI, en particular en lo que respecta a la insolvencia de grupos de empresas (Barcelona (España), 30 de agosto de 2012);

c) Participación como orador en la tercera mesa redonda sobre África de la Asociación Internacional de Profesionales en materia de Reestructuración, Insolvencia y Quiebra (INSOL International), con miras a facilitar los debates sobre la reforma de la legislación relativa a la insolvencia en África en el contexto de las cuestiones que causan particular preocupación en esa región, como las microempresas y las pequeñas empresas, así como para promover el examen de la necesidad de adoptar medidas en relación con la insolvencia transfronteriza. También celebró consultas con varias autoridades gubernamentales a fin de

examinar la propuesta de establecer un Centro Regional de la CNUDMI en Kenya (Nairobi, 6 a 9 de septiembre de 2012*).

d) Participación en el Foro Mundial sobre Derecho, Justicia y Desarrollo, organizado por el Banco Mundial, un encuentro anual ideado para examinar la manera en que la justicia y el derecho contribuyen a unos mejores resultados en el desarrollo mediante las oportunidades, la inclusión y la equidad (Washington, D.C., 10 a 14 de diciembre de 2012); y

e) Participación y presentación de ponencias en el Examen Anual del Canadá del Derecho de Quiebra, acogido por la Universidad de Columbia Británica. La conferencia es el principal encuentro sobre insolvencia celebrado en el Canadá, atrae a un número importante de especialistas del Canadá y los Estados Unidos y permite actualizarse en lo que respecta a las novedades más destacables en el derecho de quiebra (casos recientes, etc.) ocurridas en los últimos 12 meses (Montreal (Canadá), 8 y 9 de febrero de 2013).

Garantías reales

43. La Secretaría se vale de dos enfoques para prestar asistencia técnica relacionada con los textos de la CNUDMI sobre garantías reales (la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional¹², la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas¹³, su Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual¹⁴ y el proyecto de guía de la CNUDMI sobre la creación de un registro de garantías reales¹⁵). El primer enfoque se centra en divulgar información acerca de esos textos entre autoridades gubernamentales, legisladores, magistrados, académicos y expertos para, de esa manera, promover su aplicación. Con este fin la Secretaría participó en las siguientes reuniones:

a) Conferencia sobre la financiación garantizada en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y consultas con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia (Moscú, 13 a 20 de octubre de 2012);

b) Reunión de un grupo de expertos con representantes del Ministerio de Justicia y de la Cámara Federal de Notarios de la Federación de Rusia sobre el proyecto de disposiciones sobre prenda del Código Civil de la Federación de Rusia y la nueva ley de registro prendario (Viena, 27 y 28 de noviembre de 2012);

c) Conferencia sobre el registro de garantías reales en el Coloquio sobre la publicidad como factor de la eficiencia de las garantías reales, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Auvernia (Clermont-Ferrand (Francia), 1 de febrero de 2013); y

d) Conferencia sobre la financiación de la propiedad intelectual en la Universidad Lazarski/Centro de Estudios Jurídicos Internacionales, maestría en

¹² Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.04.V.14.

¹³ Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.09.V.12.

¹⁴ Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.11.V.6.

¹⁵ http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/6Security_Interests.html.

derecho en el Programa de Práctica Mercantil Transnacional (Salzburgo (Austria), 26 de marzo de 2012);

44. El segundo enfoque se centra en la prestación de asistencia técnica a los Estados en sus actividades de reforma de la legislación sobre las operaciones garantizadas. Como ejemplo de las actividades en ese ámbito se puede mencionar la asistencia técnica prestada a la Federación de Rusia respecto del derecho de prenda y el registro prendario. Otro ejemplo es la cooperación con instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y otras organizaciones, entre ellas el National Law Centre on Inter-American Free Trade, en el contexto de la asistencia técnica que presta a los Estados. El objetivo de esa cooperación es velar por que la asistencia técnica se preste de conformidad con lo dispuesto en los textos de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas. Como ejemplos de ese criterio cabe mencionar la aprobación en Colombia, Guatemala y México de leyes sobre operaciones garantizadas que se adecuan a la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas.

45. La Secretaría también celebra consultas officiosas con legisladores y funcionarios encargados de formular políticas de distintas jurisdicciones, en algunos casos como seguimiento de las actividades mencionadas. Por último, la Secretaría está progresando en su labor con el Banco Mundial con miras a preparar un conjunto de principios para operaciones garantizadas eficaces y eficientes.

Solución de controversias en línea

46. La Secretaría asistió como orador a la Conferencia de Europa sobre derecho y tecnología, donde habló sobre las últimas deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias por Vía Informática (Praga, 12 de noviembre de 2012).

Otras actividades de creación de capacidad

47. La Secretaría participó, en calidad de especialista, en la capacitación prestada por la UNCTAD en cuanto a la integración de la dimensión del comercio en los marcos de la asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo y presentó una ponencia sobre la importancia de la reforma del derecho mercantil. Esa actividad estuvo dirigida a funcionarios públicos de distintos países de Asia receptores de asistencia de las Naciones Unidas en el ámbito de la economía y el comercio. Fue este el tercero de una serie de cursos prácticos basados en el manual de capacitación elaborado por el Grupo Interinstitucional sobre Comercio y Capacidad Productiva, del cual la CNUDMI es miembro. Siguiendo la estructura del manual, el curso práctico centró su atención en distintos aspectos del comercio, entre ellos los jurídicos, que se deberían tener en cuenta al elaborar planes de desarrollo nacionales en el contexto del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) (Katmandú, 23 a 27 de abril de 2012).

48. La Secretaría también participó en otras actividades de creación de capacidad encaminadas a aumentar los conocimientos respecto del derecho mercantil internacional. Entre ellas cabe señalar la cooperación con el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (CCI-OIT) y la Universidad de Turín.

49. En el marco de esa cooperación, la Secretaría ha seguido contribuyendo a la gestión e impartición del curso de maestría en contratación pública para el

desarrollo sostenible y el curso de maestría en derecho mercantil internacional. Esos cursos a nivel de maestría son parte integrante del programa educativo más amplio denominado “Escuela de Desarrollo de Turín”¹⁶.

50. Tal vez los organismos de desarrollo internacional y otras instituciones que gestionan programas amplios de asistencia técnica deseen considerar la posibilidad de patrocinar la participación de estudiantes en esos cursos, a fin de reforzar la capacidad local a largo plazo de los países asociados.

III. Actividades del Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico

51. Desde la celebración del 45º período sesiones de la Comisión, el Centro Regional para Asia y el Pacífico ha llevado a cabo sus actividades siguiendo los criterios de actuación de la Secretaría en materia de asistencia técnica (A/66/17, párr. 255), así como las prioridades concretas determinadas por el Centro Regional (A/67/17, párr. 184), a saber, la evaluación de las necesidades y la localización de los proyectos existentes de reforma del derecho mercantil con miras a intensificar la coordinación entre ellos, y el establecimiento de contactos con las entidades que ya participan significativamente en la reforma del derecho mercantil. Se ha prestado particular importancia a la coordinación con otras entidades regionales y, entre ellas, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP). También se han establecido contactos con los centros de información de las Naciones Unidas en Australia y el Japón a fin de que las actividades del Centro Regional y las iniciativas de reforma legislativa sean más difundidas por la prensa.

52. Habida cuenta de las iniciativas y solicitudes existentes, el Centro Regional mantuvo su atención en las zonas geográficas de Asia oriental y el Pacífico y en las esferas temáticas relacionadas con los mecanismos alternativos de solución de controversias, la compraventa de mercaderías y el comercio electrónico. Se ha procurado establecer una cooperación más estrecha con instituciones que ya participan en ese ámbito, como la Oficina de Enlace y Coordinación del Pacífico del Banco Asiático de Desarrollo, ubicada en Sydney (Australia), que participa activamente en la reforma de la legislación mercantil en apoyo del desarrollo del sector privado en el Pacífico, el Instituto de Investigaciones Legislativas de la República de Corea y el Centro Asiático de Intercambio Jurídico de la Universidad de Nagoya (Japón).

53. La labor del Centro Regional reflejó el interés de los Estados y otros interesados en el uso de textos uniformes en la reforma del derecho mercantil como medio de aumentar la previsibilidad jurídica y reducir los costos del comercio transfronterizo. Este interés es todavía mayor porque no existen organizaciones regionales de integración económica con autoridad amplia para la promulgación de normas y habida cuenta del amplio apoyo expresado por varios Estados de Asia y el Pacífico en lo que respecta al logro del desarrollo económico como cuestión prioritaria.

54. En lo que respecta a la formulación de políticas, el Centro Regional contribuyó al debate sobre la relación existente entre las reformas del derecho mercantil

¹⁶ <http://www.itcilo.org/en/training-offer/turin-school-of-development-1>.

basadas en textos uniformes, el desarrollo económico como agente catalizador de la estabilidad social y la prevención de conflictos, y el estado de derecho (por ejemplo, en un curso práctico celebrado en la Universidad de Hokkaido, Sapporo (Japón), el 22 de febrero de 2013).

55. Se emprendieron varias iniciativas a nivel operacional.

56. Los mecanismos alternativos de solución de controversias atraen un constante interés en la región por distintas razones. Según una opinión muy difundida, los valores asiáticos favorecen la armonía y la reconciliación en lugar de los métodos contradictorios para la solución de controversias. Esa actitud, por ejemplo, tal vez exija una separación menos estricta entre los procedimientos de conciliación y arbitraje. Además, la participación cada vez mayor de los países de Asia en el comercio y las inversiones internacionales, incluso como inversionistas, ha aumentado su exposición al arbitraje internacional. Por último, se ha invocado el arbitraje cada vez más como el método preferido de solución de controversias también para las controversias internacionales que no tienen carácter mercantil. Todos estos factores se suman para aumentar el interés por los mecanismos alternativos de solución de controversias en la región y la demanda de actividades conexas de creación de capacidad.

57. En esa esfera, el Centro Regional organizó con el Ministerio de Justicia y la Junta de Arbitraje Mercantil de la República de Corea una importante reunión sobre las perspectivas de Asia y el Pacífico respecto del arbitraje mercantil internacional (Seúl, 22 y 23 de noviembre de 2012), en la que se examinaron todos los textos de la CNUDMI relativos al arbitraje, así como la labor que realiza actualmente en esa esfera. Se prevé celebrar esa reunión anualmente. Entre otras actividades relativas a los mecanismos alternativos de solución de controversias en las que el Centro Regional ha participado cabe mencionar la Conferencia de Mediación de Asia y el Pacífico de 2012: la mediación y sus efectos en los ordenamientos jurídicos nacionales, organizada por la City University de Hong Kong (Hong Kong (China), 16 y 17 de noviembre de 2012), así como un curso práctico sobre arbitraje mercantil internacional organizado por la Academia Real de Profesiones Jurídicas del Reino de Camboya (Phnom Penh, 9 de agosto de 2012). En particular, ese curso práctico tuvo como objetivo aumentar la familiaridad del poder judicial de Camboya con la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (1958) (la “Convención de Nueva York”) y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (la “Ley Modelo sobre Arbitraje”), ya que ambos textos han sido adoptados por Camboya.

58. Además, se ha realizado una labor importante para crear conciencia y promover el uso del Compendio de la CNUDMI de jurisprudencia sobre la Ley Modelo de 2012, instrumento que ha causado gran interés y recibido elogios generales (véase el párr. 25). La Ley Modelo sobre Arbitraje ha sido adoptada ampliamente en Asia y el Pacífico, y en algunas subregiones, como Asia sudoriental, se considera un estándar de hecho. Entre las promulgaciones recientes de esa Ley Modelo en la región cabe mencionar, según distintas fuentes, la nueva Ley de arbitraje de la Arabia Saudita (Decreto Real núm. M/34, de fecha 24/5/1433 H/ 16 de abril de 2012).

59. El Centro Regional ha procurado activamente promover la participación universal de la región en la Convención de Nueva York. En tal sentido, cabe señalar

que el 14 de agosto de 2012 Tayikistán pasó a ser parte en la Convención de Nueva York. Ello se promovió mediante un proyecto de creación de capacidad en apoyo de la adhesión de Tayikistán a la Organización Mundial del Comercio, patrocinado por el USAID. El Centro Regional ha seguido de cerca el proceso de examen de la adhesión a la Convención de Nueva York por Myanmar, incluso contribuyendo a actividades específicas al respecto (Yangón (Myanmar), 12 de diciembre de 2012). Se prestó especial atención a la importancia de ese tratado en el contexto de la armonización de la normativa de arbitraje en los Estados miembros de la ASEAN, incluso mediante una contribución a un curso práctico de la Reunión de Altos Funcionarios Jurídicos de la ASEAN sobre armonización de la legislación mercantil en los Estados miembros de la ASEAN (Singapur, 11 y 12 de marzo de 2013). El 16 de abril de 2013, Myanmar pasó, a ser el 149º Estado parte en la Convención de Nueva York.

60. También se prestó atención especial a la promoción de la adopción de la Convención de Nueva York en los pequeños Estados insulares del Pacífico, una de las regiones del mundo en las que la tasa de adopción de dicho tratado es más baja. Se han establecido contactos con asociados potencialmente interesados en contribuir a actividades encaminadas a promover la participación en la Convención mediante la creación de la capacidad jurídica correspondiente, a fin de que los pequeños Estados insulares del Pacífico puedan contar con un instrumento jurídico fundamental para su integración más estrecha en la economía regional y mundial.

61. Se ha realizado directamente con los interesados una labor importante respecto de la compraventa internacional de mercaderías y, en particular, la promoción de la adopción y la interpretación uniforme de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, de 1980 (CIM). El tema se trató frecuentemente en las actividades de promoción, como el curso práctico sobre “Textos de la CNUDMI en Australia: arbitraje, comercio electrónico, compraventa de mercaderías”, organizado conjuntamente con el Grupo de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Monash (Melbourne, Australia, 7 de febrero de 2013), y la conferencia “Del ámbito mundial al local”, organizada por el Instituto de Árbitros y Mediadores de Nueva Zelanda (AMINZ) (Wellington, 2 a 4 de agosto de 2012), en la que también se presentaron ponencias sobre arbitraje y comercio electrónico.

62. Desde el punto de vista legislativo, cabe destacar el retiro por la República Popular China de la declaración relativa a los artículos 11, 12 y 96 de la CIM, en el marco de la tendencia mundial a examinar y, si procede, retirar las declaraciones vigentes a fin de aumentar la uniformidad del alcance de la aplicación del tratado. La cuestión se había examinado por primera vez en la secretaría de la CNUDMI en el seminario internacional sobre “Interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CIM), con hincapié en los litigios y el arbitraje en China”, celebrado en la Universidad de Wuhan (Wuhan (China), 13 y 14 de octubre de 2007) (A/CN.9/652, párr. 10 b)). Entre las posibles nuevas partes, Viet Nam ha informado de progresos respecto de la adopción de la CIM, después de la conclusión positiva de una consulta pública sobre la cuestión.

63. El Centro Regional ha sido particularmente activo en la esfera del comercio electrónico promoviendo la aprobación de los textos existentes y participando en foros regionales, algunos de ellos destinados a la elaboración de futuros estándares

regionales. La información reunida indica que entre los Estados hay distintos niveles de concienciación e interés en la legislación del comercio electrónico. Por ejemplo, varios países de Asia oriental y sudoriental cuentan con legislación nacional suficientemente desarrollada en esa esfera y en la actualidad están abordando sus aspectos internacionales, lo que comprende la consideración de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, de 2005. Por otra parte, la mayor parte de los países de Asia meridional aparentemente dan prioridad al fortalecimiento de su marco legislativo nacional, y algunos Estados de Asia central se encuentran en las etapas preliminares de la preparación de legislación nacional.

64. En tal sentido, cabe observar que los textos de la CNUDMI sobre el comercio electrónico se consideran el estándar de hecho para la armonización subregional entre los Estados miembros de la ASEAN. Recientemente se dio un nuevo paso en tal sentido con la adopción por la República Democrática Popular Lao de la Ley sobre operaciones electrónicas (Ley núm. 20/NA, de 7 de diciembre de 2012, promulgada mediante el decreto presidencial núm. 025/POR, de 17 de enero de 2013). El Centro Regional participó en el “Curso práctico preparatorio ASEAN/UNCTAD sobre el examen de la armonización de las leyes de comercio electrónico en la ASEAN” (Cebú (Filipinas), 10 y 11 de noviembre de 2012) y contribuyó a las actividades de examen posteriores, coordinadas por la secretaria de la ASEAN y la UNCTAD, y que culminaron en la preparación de un estudio que contiene recomendaciones sobre cómo continuar la armonización de la legislación del comercio electrónico en la ASEAN.

65. Entre otras tareas realizadas por el Centro Regional en la esfera del comercio electrónico se pueden mencionar la explicación de las ventajas que supone la adopción de los textos uniformes de la CNUDMI en el contexto de un marco jurídico propicio para los servicios electrónicos de ventanilla única (“Reunión Plenaria y EDICOM de 2012 del Consejo de Asia y el Pacífico para la Facilitación del Comercio y las Operaciones Electrónicas (AFACT)”, Teherán, 21 y 22 de noviembre de 2012); y la contribución a la labor realizada por la CESPAP y la Red de expertos de las Naciones Unidas para el comercio sin soporte de papel en Asia y el Pacífico (UN NExT), en cumplimiento de lo establecido en la resolución núm. 68/3 de la CESPAP y con miras a evaluar la conveniencia y viabilidad de un acuerdo regional sobre el comercio sin soporte de papel (“Consulta regional de expertos sobre la conectividad en la sociedad digital de Asia y el Pacífico a fin de promover la resiliencia”, Colombo, 5 y 6 de septiembre de 2012; “Reunión del grupo de expertos para el mejoramiento de la conectividad regional mediante el comercio y las inversiones: arreglos regionales para la facilitación del comercio transfronterizo sin soporte de papel”, Bangkok, 13 y 14 de marzo de 2013). El Centro Regional organizó otras reuniones con el objetivo, entre otras cosas, de promover la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (2005), en colaboración con la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros (Seúl, 20 y 21 de septiembre de 2012) y la Facultad de Derecho TC Beirne de la Universidad de Queensland (Brisbane (Australia), 5 de febrero de 2013).

66. Además, el Centro Regional ha apoyado activamente la labor de la CNUDMI relacionada con la preparación de textos legislativos, tanto la actual como la que

posiblemente llevará a cabo en el futuro. En particular, se convocó una reunión de un grupo de expertos para examinar el uso de textos uniformes en las actividades en curso de reforma del derecho contractual y los medios posibles para mejorar la coordinación entre la legislación mundial, regional y nacional (Incheón (República de Corea), 25 y 26 de febrero de 2013). En esa reunión se destacó la importancia que se otorgaba a la legislación uniforme en la reforma del derecho contractual de ciertos países de Asia oriental, la necesidad de aumentar la labor de promoción, especialmente en los países en desarrollo, de explicar cabalmente las características de los textos uniformes y las ventajas que supondría su adopción, y la conveniencia de trabajar en coordinación más estrecha y respaldar las actividades regionales encaminadas a preparar nuevos textos uniformes. Entre otras reuniones pertinentes cabe mencionar una conferencia organizada conjuntamente con la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros (Seúl, 20 y 21 de septiembre de 2012), en la que, entre otras cosas, se examinaron cuestiones relacionadas con la labor del Grupo de Trabajo III (Solución de Controversias en Línea) y el Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) de la CNUDMI.

67. El Centro Regional ha participado en varias reuniones celebradas para difundir información y crear capacidad en el país anfitrión, la República de Corea, como el seminario sobre “Cuestiones prácticas actuales de la compraventa internacional de mercaderías y el arbitraje mercantil internacional”, organizado conjuntamente por el Centro Regional y la Oficina de Asia de la International Bar Association (Seúl, 12 de julio de 2012), la conferencia “Tendencias recientes en el derecho de las operaciones comerciales internacionales en Asia”, organizada por la Universidad Dong-A (Busán, 8 y 9 de noviembre de 2012) y la conferencia especial “La CNUDMI y los problemas actuales en la armonización del derecho mercantil”, en la Universidad Nacional de Seúl (Seúl, 20 de noviembre de 2012).

68. La plantilla del Centro Regional cuenta con un funcionario del Cuadro Orgánico y un auxiliar, además de un experto jurídico aportado por el Gobierno de la República de Corea a título no reembolsable. El Centro Regional acoge pasantes periódicamente. El presupuesto del proyecto, financiado en su totalidad por el Gobierno de la República de Corea, permite contratar ocasionalmente a expertos y consultores. Además, el Centro Regional a menudo ha podido valerse de los recursos de sus asociados, especialmente para contribuir a los gastos de viaje y las instalaciones y servicios de reuniones.

69. El Centro Regional ha recibido de la CESPAP, en particular de su Oficina Subregional para Asia Oriental y Asia Nororiental, también ubicada en Incheón, apoyo respecto de distintas funciones administrativas fundamentales para el cumplimiento de su mandato. Esa asistencia se ofrece a título provisional, hasta que se concluya un arreglo oficial entre la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas y la CESPAP.

70. Se espera que las actividades futuras del Centro Regional generen mayor interés en los textos de la CNUDMI y nuevas solicitudes de asistencia técnica. Ese aumento hará necesario un incremento correspondiente de los recursos disponibles. En particular, esos recursos se podrían otorgar haciendo todavía más hincapié en la contribución fundamental de la reforma del derecho mercantil a los principales objetivos normativos internacionales, como el estado de derecho y la lucha contra la pobreza y, en consecuencia, incorporando las actividades de reforma del derecho mercantil a los programas vigentes de asistencia para el desarrollo.

IV. Difusión de información

71. Diversos documentos y publicaciones preparados por la CNUDMI constituyen instrumentos fundamentales para sus actividades de cooperación y asistencia técnicas, en particular para la difusión de información sobre su labor y sus textos.

A. Sitio de la CNUDMI en Internet

72. El sitio de la CNUDMI en Internet, que puede consultarse en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, contiene los documentos íntegros de la Comisión y otro material relativo a su labor, como publicaciones, información sobre el estado de aplicación de los tratados, comunicados de prensa, últimos acontecimientos y noticias. En consonancia con la política de la organización en relación con la distribución de los documentos, se proporciona acceso a los documentos oficiales disponibles mediante enlaces con el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (ODS).

73. En 2012, el sitio recibió aproximadamente 500.000 visitantes únicos. Si bien en comparación con 2011 aumentó el número general de visitantes, el mayor aumento de tráfico se observó en las páginas en idiomas distintos del inglés. Aproximadamente el 58% del tráfico se dirigió a las páginas en inglés, el 27% a las páginas en español y francés (frente al 22% registrado en 2011) y el 15% restante a las páginas en árabe, chino y ruso (frente al 11% registrado en 2011). En tal sentido, cabe señalar que si bien el sitio de la CNUDMI es una de las fuentes electrónicas más importantes de información sobre derecho mercantil internacional en todos los idiomas, en algunos de los idiomas oficiales quizás sea una de las pocas fuentes disponibles sobre el tema.

74. El contenido del sitio se actualiza y amplía continuamente en el marco de las actividades de la Biblioteca Jurídica de la CNUDMI y, en consecuencia, no entraña un gasto adicional para la Secretaría. En particular, los documentos oficiales de la CNUDMI relativos a períodos de sesiones anteriores de la Comisión se cargan continuamente en el ODS y pueden consultarse en el sitio en virtud de un proyecto de digitalización de los archivos de la CNUDMI ejecutado conjuntamente con la Dependencia de Gestión de Documentos de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV).

B. Biblioteca

75. Desde su creación en 1979, la Biblioteca Jurídica de la CNUDMI ha estado al servicio de las necesidades de investigación del personal de la Secretaría y los participantes en las reuniones intergubernamentales organizadas por la Comisión. También ha asistido en su labor de investigación al personal de las misiones permanentes, el personal de las Naciones Unidas en todo el mundo, el personal de otras organizaciones internacionales con sede en Viena, investigadores externos y estudiantes de derecho. En 2012 el personal de la biblioteca dio respuesta a unas 475 solicitudes de consulta (un aumento del 36% respecto de 2011) originadas en más de 45 países.

76. La colección de la Biblioteca Jurídica de la CNUDMI se compone principalmente de textos sobre derecho mercantil internacional y actualmente comprende más de 10.000 monografías, 100 títulos de revistas en circulación, documentación de referencia de carácter jurídico y general, incluidos documentos de otras entidades de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, y recursos electrónicos (para su utilización interna únicamente). Se presta particular atención a la ampliación de la colección en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Si bien ha aumentado el uso de los recursos electrónicos, respecto de muchos países los recursos sobre derecho mercantil solo se encuentran impresos, y la circulación de los artículos impresos ha permanecido constante.

77. La Biblioteca Jurídica de la CNUDMI mantiene un catálogo en línea de acceso público junto con las demás bibliotecas de las Naciones Unidas en Viena y con el apoyo técnico de la Biblioteca de las Naciones Unidas en Ginebra. Se puede acceder al catálogo a través de la página de la biblioteca del sitio de la CNUDMI en Internet.

78. El personal de la Biblioteca Jurídica prepara para la Comisión una bibliografía anual de obras relacionadas con la labor de la CNUDMI. La bibliografía incluye referencias a libros, artículos y ponencias en diversos idiomas, clasificados por temas (en relación con el 46º período de sesiones de la Comisión, véase el documento A/CN.9/772). Cada ficha bibliográfica se incorpora al catálogo en línea de acceso público y los textos íntegros de todos los materiales citados se mantienen en la colección de la Biblioteca. En la sección de bibliografía del sitio de la CNUDMI en Internet figuran actualizaciones mensuales a partir de la fecha de la última bibliografía anual.

79. La Biblioteca presenta en el sitio de la CNUDMI en Internet¹⁷ una bibliografía consolidada de obras relacionadas con la labor de la Comisión en la que se recogen todos los registros de los informes bibliográficos presentados anualmente a la Comisión desde 1968. La bibliografía consolidada contiene actualmente más de 6.500 registros, reproducidos en inglés y en los idiomas originales, verificados y normalizados en la medida de lo posible.

C. Publicaciones

80. Además de los documentos oficiales, la CNUDMI ha venido manteniendo dos series de publicaciones, a saber, los textos de todos los instrumentos preparados por la Comisión y el *Anuario* de la CNUDMI. Periódicamente se distribuyen publicaciones en apoyo de las actividades de cooperación y asistencia técnicas realizadas por la Secretaría, así como por otras organizaciones en las que se examina la labor de la CNUDMI, y en el contexto de la labor de reforma de las leyes nacionales.

81. En 2012 se publicaron las obras siguientes: La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial¹⁸; un folleto revisado sobre la Convención sobre la prescripción en materia de compraventa

¹⁷ Se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/publications/bibliography_consolidated.html.

¹⁸ Se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/insolvency.html.

internacional de mercaderías de 1974, con una nota explicativa¹⁹; Textos sobre garantías reales preparados por la CNUDMI, la Conferencia de La Haya y el UNIDROIT: comparación y análisis de las principales características de los instrumentos internacionales relacionados con las operaciones garantizadas²⁰; Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia, Tercera parte: trato otorgable a los grupos de empresas en situaciones de insolvencia²¹; Compendio de la CNUDMI sobre jurisprudencia relativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, edición de 2012 (en inglés)²²; Compendio de la CNUDMI sobre jurisprudencia relativa a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, edición de 2012 (en inglés)²³; y los *Anuarios* de la CNUDMI de 2008 y 2009 (en inglés)²⁴.

82. A comienzos de 2013 se publicaron las obras siguientes: Recomendaciones para ayudar a las instituciones arbitrales y a otros órganos interesados en relación con los arbitrajes regidos por el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (revisado en 2010)²⁵, y Guía de la CNUDMI: Datos básicos y funciones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional²⁶.

83. A la luz de las preocupaciones ambientales y presupuestarias, la Secretaría ha seguido haciendo todo lo posible por utilizar los medios electrónicos como principal método para difundir los textos de la CNUDMI. Así pues, se ha reducido la tirada de todas las publicaciones y varios de los textos de 2012 se han publicado exclusivamente en formato electrónico, a saber: La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: la perspectiva judicial (libro electrónico); el folleto revisado sobre la Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías (libro electrónico); Compendio de la CNUDMI sobre jurisprudencia relativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, edición de 2012 (en inglés) (CD-ROM y libro electrónico); y los *Anuarios* de la CNUDMI de 2008 y 2009 (en inglés) (CD-ROM y libro electrónico).

D. Comunicados de prensa

84. Habitualmente se emiten comunicados de prensa cuando se adoptan medidas sobre tratados relacionados con la CNUDMI o se recibe información sobre la adopción de una ley modelo de la Comisión u otro texto pertinente. También se emiten comunicados de prensa con respecto a información que tenga particular importancia e interés directo para la CNUDMI. Esos comunicados se transmiten por correo electrónico a las partes interesadas y se publican en el sitio de la Comisión en Internet y, en su caso, en el del Servicio de Información de las Naciones Unidas en Viena, o del Departamento de Información Pública de la División de Noticias y Medios de Información de Nueva York.

¹⁹ Se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/sale_goods.html.

²⁰ Se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/security.html.

²¹ Se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/insolvency.html.

²² Se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/case_law/digests.html.

²³ Se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/case_law/digests.html.

²⁴ Se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/en/publications/yearbook.html.

²⁵ Se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration.html.

²⁶ Se puede consultar en www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html.

85. Dado que la adopción de leyes modelo de la CNUDMI no requiere un trámite oficial ante la Secretaría de las Naciones Unidas, para que la información que se recibe a ese respecto sea más precisa y oportuna y para facilitar la difusión de información conexas la Comisión tal vez desee solicitar a los Estados Miembros que notifiquen a la Secretaría cuando promulguen leyes por las que apliquen una ley modelo de la Comisión.

E. Consultas generales

86. Actualmente la Secretaría atiende alrededor de 2.000 consultas generales al año que se refieren, entre otras cosas, a aspectos técnicos y a la disponibilidad de textos de la CNUDMI, documentos de trabajo, documentos de la Comisión y cuestiones conexas. Cada vez en mayor medida se responde a esas consultas remitiendo al interesado al sitio de la CNUDMI en Internet.

F. Sesiones de información para las misiones permanentes acreditadas en Viena

87. El 4 de diciembre de 2012, la Secretaría presentó información sobre la CNUDMI y sus métodos de trabajo en el marco del seminario de orientación para los miembros de las misiones permanentes acreditadas ante los organismos internacionales en Viena organizado por el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y la Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

G. Conferencias informativas en Viena

88. Previa solicitud, la Secretaría ofrece conferencias informativas a nivel interno sobre la labor de la CNUDMI a docentes y estudiantes universitarios, letrados, funcionarios públicos, incluidos magistrados, y otros interesados. Desde que se presentó el último informe se han ofrecido conferencias a visitantes de la Arabia Saudita, Austria, Eslovenia, Hungría e Irlanda, así como a una delegación de la Sección de Derecho Internacional de la American Bar Association.

V. Recursos y financiación

89. La mayor parte de los gastos por concepto de actividades de cooperación y asistencia técnicas no se sufragan con cargo al presupuesto ordinario. Por consiguiente, la capacidad de la Secretaría para ejecutar el componente de cooperación y asistencia técnicas del programa de trabajo de la CNUDMI depende de los fondos extrapresupuestarios disponibles.

90. La Secretaría ha estudiado diversos medios para incrementar los recursos dedicados a las actividades de asistencia técnica, incluso mediante contribuciones en especie. En particular, varias misiones han sido financiadas, en su totalidad o en parte, por los organizadores. Se podría disponer de otras fuentes de financiación si las actividades de reforma del derecho mercantil pudieran integrarse con más

regularidad en programas internacionales más amplios de asistencia para el desarrollo. A este respecto, la Comisión tal vez desee ofrecer orientación sobre medidas que pudieran adoptarse en el futuro.

A. Fondo Fiduciario para Simposios de la CNUDMI

91. El Fondo Fiduciario para Simposios de la CNUDMI apoya las actividades de cooperación y asistencia técnicas destinadas a los miembros de la comunidad de juristas de los países en desarrollo financiando la participación de funcionarios de la Comisión u otros expertos en seminarios en que se presenten textos de la CNUDMI para su examen y posible adopción, así como misiones de determinación de los hechos para evaluar, con miras a una reforma legislativa, la legislación interna en vigor y las necesidades de los países en materia de reforma de la legislación mercantil.

92. Durante el período que se examina, el Gobierno de la República de Corea hizo una contribución de 13.878,61 dólares por conducto de su Ministerio de Justicia, para la participación de la secretaría de la CNUDMI en el proyecto del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico relativo a la facilidad para efectuar operaciones comerciales (véase el párr. 11). En 2012 también se recibió una nueva contribución de 20.000 dólares, así como una nueva promesa por 20.000 dólares para 2013, del Gobierno de Indonesia. La Comisión tal vez desee expresar su gratitud a ambos gobiernos.

93. En su 45º período sesiones (Nueva York, 25 de junio a 6 julio de 2012), la Comisión hizo un llamamiento a todos los Estados, organizaciones internacionales y otras entidades interesadas a fin de que estudiaran la posibilidad de contribuir al Fondo Fiduciario para Simposios de la CNUDMI, de ser posible en forma de contribuciones plurianuales o contribuciones para fines concretos, con miras a facilitar la planificación y dotar a la Secretaría de los medios necesarios para atender al número cada vez mayor de solicitudes de actividades de cooperación y asistencia técnicas presentadas por países en desarrollo y países de economía en transición (A/67/17, párrs. 146 a 148). También se ha apelado a algunos posibles donantes a título individual.

94. La Comisión tal vez considere oportuno observar que, pese a los esfuerzos desplegados por la Secretaría para obtener nuevas donaciones, los recursos restantes en el Fondo Fiduciario solo serán suficientes para seguir financiando un número muy reducido de actividades de cooperación y asistencia técnicas. Se sigue procurando organizar las actividades solicitadas al menor costo posible y mediante la financiación conjunta y la distribución de los gastos, siempre que resulte posible. No obstante, una vez agotados los fondos, las peticiones de cooperación y asistencia técnicas que entrañen gastos de viaje u otros gastos conexos tendrán que denegarse, a menos que el Fondo Fiduciario reciba nuevas donaciones o que se encuentren otras fuentes de financiación.

95. La Comisión tal vez desee formular de nuevo un llamamiento a todos los Estados, organismos y órganos competentes de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y otras entidades interesadas para que efectúen contribuciones al Fondo Fiduciario, de ser posible con carácter plurianual, a fin de facilitar la planificación y permitir que la Secretaría responda a las solicitudes en materia de

cooperación y asistencia técnicas y elabore un programa de asistencia técnica más sostenido y sostenible. La Comisión tal vez desee también pedir a los Estados Miembros que ayuden a la Secretaría a encontrar fuentes de financiación en sus respectivas administraciones.

B. Fondo Fiduciario de la CNUDMI destinado a conceder asistencia para gastos de viaje a los países en desarrollo que la integran

96. La Comisión tal vez desee recordar que, de conformidad con la resolución 48/32 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1993, se pidió al Secretario General que estableciera un fondo fiduciario destinado a conceder asistencia para gastos de viaje a los países en desarrollo miembros de la CNUDMI. El Fondo establecido conforme a esa resolución puede recibir contribuciones financieras voluntarias de Estados, organizaciones intergubernamentales, organizaciones regionales de integración económica, instituciones nacionales y organizaciones no gubernamentales, así como de personas físicas y jurídicas.

97. En el período que se examina, se recibió una contribución por valor de 5.000 euros del Gobierno de Austria, al que la Comisión tal vez desee expresar su gratitud.

98. En 2012 los recursos de que disponía el Fondo Fiduciario se utilizaron para facilitar la participación de los delegados de Colombia, El Salvador y Honduras en el 45º período de sesiones de la Comisión, celebrado en Nueva York en julio. Debido a lo reducido de los recursos, solo se sufragaron los gastos correspondientes a los pasajes aéreos de los tres delegados.

99. Para asegurar la participación de todos los Estados Miembros en los períodos de sesiones de la CNUDMI y sus grupos de trabajo, la Comisión tal vez desee reiterar su llamamiento a los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones y las instituciones, así como a los particulares, para que efectúen contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario destinado a conceder asistencia para gastos de viaje a los países en desarrollo que son miembros de la Comisión.

100. Cabe recordar que en su resolución 51/161, de 16 de diciembre de 1996, la Asamblea General decidió incluir los fondos fiduciarios de la CNUDMI para simposios y para la concesión de asistencia para gastos de viaje en la lista de fondos y programas que se examinan en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Promesas de Contribuciones para las Actividades de Desarrollo.

X. SITUACIÓN ACTUAL Y PROMOCIÓN DE LOS TEXTOS JURÍDICOS DE LA CNUDMI

Nota de la Secretaría sobre la situación actual de las convenciones y leyes modelo

(A/CN.9/773)

[Original: inglés]

No se reproduce. Puede obtenerse información actualizada de la secretaría de la CNUDMI o en Internet en el sitio www.uncitral.org.

XI. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

Nota de la Secretaría sobre actividades de coordinación

(A/CN.9/776)

[Original: inglés]

Índice

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-4
II. Actividades de coordinación	5-27
A. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado	5-10
B. Otras organizaciones	11-27

I. Introducción

1. En la resolución 34/142, de 17 de diciembre de 1979, la Asamblea General pidió al Secretario General que presentara a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) un informe sobre las actividades jurídicas de las organizaciones internacionales en materia de derecho mercantil internacional, junto con recomendaciones sobre las medidas que debería adoptar la Comisión para cumplir su mandato de coordinación de las actividades de otras organizaciones en esa materia.

2. En la resolución 36/32, de 13 de noviembre de 1981, la Asamblea General hizo suyas diversas sugerencias de la Comisión para seguir desempeñando su función de coordinación de las actividades relacionadas con el derecho mercantil internacional¹. Entre esas sugerencias estaba la de que, además de un informe general sobre las actividades jurídicas de las organizaciones internacionales, se presentaran informes sobre determinadas actividades relativas a tareas ya en curso y a otras en que aún no se hubiera emprendido una labor de unificación, pero en las que pudiera convenir hacerlo².

3. En el presente informe, preparado en cumplimiento de la resolución 34/142 y de conformidad con el mandato de la CNUDMI³, se proporciona información sobre las actividades de otras organizaciones internacionales que se ocupan del derecho mercantil internacional y en las que ha participado la Secretaría de la Comisión, principalmente grupos de trabajo, grupos de expertos y sesiones plenarias. La finalidad de esa participación ha sido asegurar la coordinación de las actividades de las diferentes organizaciones en la materia, compartir información y conocimientos

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/36/17), párrs. 93 a 101.*

² *Ibid.*, párr. 100.

³ Véase la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, secc. II, párr. 8.

especializados y evitar la duplicación de las tareas y de los productos derivados de ellas.

4. Tal vez la Comisión desee tomar nota de la participación cada vez mayor de la Secretaría en las iniciativas de otras organizaciones. Esta ha sido una pauta sostenida en los últimos años, congruente con la intensificación de las actividades de asistencia técnica de la Secretaría⁴, que se prevé mantener e incluso reforzar en el futuro.

II. Actividades de coordinación

A. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT)

5. La Secretaría participó en el 91º período de sesiones del Consejo de Administración del UNIDROIT (Roma, 7 a 9 de mayo de 2012). En dicho período de sesiones, el Consejo expresó su satisfacción por el hecho de que se hubiera incluido en el programa del 45º período de sesiones de la CNUDMI la petición del UNIDROIT de que se respaldaran oficialmente sus Principios sobre los contratos comerciales internacionales de 2010.

6. La Secretaría asistió a los períodos de sesiones primero y segundo del Comité de peritos gubernamentales sobre la ejecutabilidad de las disposiciones sobre compensación global de clausura (Roma, 1 a 5 de octubre de 2012 y 4 a 9 de marzo de 2013) a fin de supervisar las tratativas y garantizar su coherencia con los textos de la CNUDMI relativos a la insolvencia y las operaciones garantizadas. El proyecto de texto quedó terminado en el segundo período de sesiones, y en mayo de 2013 se remitirá al Consejo de Administración del UNIDROIT para su aprobación. El texto definitivo es congruente, en general, con el de los documentos pertinentes de la CNUDMI.

7. La Secretaría presentó al grupo de trabajo del UNIDROIT encargado de preparar cláusulas modelo observaciones sobre un documento de posición relativo al derecho contractual, titulado “*Model Clauses for Use of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts in Transnational Contract and Dispute Resolution Practice*” (Roma, 11 y 12 de febrero de 2013).

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

8. La Secretaría asistió a la reunión de la comisión especial de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre la elección del derecho aplicable en los contratos internacionales. El resultado de esa reunión fue un instrumento no vinculante, en forma de un conjunto de principios, que en abril de 2013 se sometería al examen del Consejo de Asuntos Generales y Política, antes de que la comisión especial prosiguiera su labor relativa al comentario (La Haya (Países Bajos), 12 a 16 de noviembre de 2012).

⁴ Véase A/CN.9/775.

9. La Secretaría participó en la reunión del Consejo de Asuntos Generales y Política de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (La Haya (Países Bajos), 9 a 11 de abril de 2013). Entre otras cosas, ello fue ocasión para que la Secretaría felicitara al Secretario General saliente de la Conferencia, Sr. Hans van Loon, por su fructífero mandato, agradeciera la cooperación de la Conferencia con la CNUDMI y diera la bienvenida a su sucesor, el Sr. Christophe Bernasconi. En la reunión se informó a los participantes sobre las actividades recientes de la Conferencia, como la apertura de su oficina regional en Hong Kong, en diciembre de 2012, y se examinó el texto preparado por el grupo de trabajo sobre la elección del derecho aplicable en los contratos internacionales (véase el párrafo 7). La CNUDMI seguirá participando como observadora en la labor de ese grupo de trabajo, que debe presentar al Consejo en su próxima reunión, prevista para abril de 2014, el texto definitivo y el comentario.

Actividades conjuntas con el UNIDROIT y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

10. El UNIDROIT acogió la reunión anual de coordinación con la Secretaría de la CNUDMI y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en la que se examinó la labor actual de las tres organizaciones y los posibles ámbitos de cooperación (Roma, 5 de junio de 2012). En esa ocasión, las secretarías del UNIDROIT y de la Conferencia agradecieron a la Secretaría de la CNUDMI por haber coordinado y patrocinado la publicación sobre la labor de las tres organizaciones en lo tocante al régimen de las operaciones garantizadas⁵.

B. Otras organizaciones

11. La Secretaría ha realizado otras actividades de coordinación con varias organizaciones internacionales. Entre otras cosas, formuló observaciones sobre documentos elaborados por esas organizaciones y participó en diversas reuniones y conferencias para informar sobre la labor de la CNUDMI o exponer sus puntos de vista sobre los asuntos que se examinaban.

1. Observaciones generales

12. La Secretaría sigue participando resueltamente en las actividades del Grupo entre organismos sobre comercio y capacidad productiva⁶. En ese contexto, participó en la negociación del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) para Nepal. En el MANUD se articula la respuesta colectiva del sistema de las Naciones Unidas ante las prioridades nacionales de desarrollo mediante la coordinación de la contribución de los organismos del sistema teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países.

⁵ Véanse los textos sobre garantías reales preparados por la CNUDMI, la Conferencia de La Haya y el UNIDROIT: Comparación y análisis de las principales características de los instrumentos internacionales relacionados con las operaciones garantizadas, en www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/security/2011UNCITRAL_HCCH_Unidroit_texts.html; véanse también A/CN.9/720 y A/CN.9/749.

⁶ Véase A/CN.9/725.

13. La Secretaría presentó una ponencia sobre la armonización del derecho contractual en los planos mundial y regional en una conferencia sobre derecho privado europeo celebrada en la Universidad de Roma (Roma, 10 de mayo de 2012).

14. La Secretaría asistió a la Reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho, en la que el Presidente de la CNUDMI formuló una declaración oficial dirigida a los Estados Miembros, las organizaciones no gubernamentales y los representantes de la sociedad civil allí presentes (Nueva York, Estados Unidos de América, 23 y 24 de septiembre de 2012). En esa declaración reconoció la importancia de unos marcos jurídicos justos, estables y previsibles para crear desarrollo y crecimiento económico inclusivos, sostenibles y equitativos y encomió la labor realizada por la CNUDMI para modernizar y armonizar el derecho mercantil internacional.

15. Como el año anterior, la Secretaría asistió a la reunión anual del consejo consultivo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sobre el derecho internacional privado (Washington, D.C. 11 y 12 de octubre de 2012).

16. La Secretaría participó en la Semana Europea de las Microfinanzas de 2012, organizada por la Plataforma Europea de Microfinanzas, a la que asistieron representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, círculos académicos y el sector privado de todo el mundo que se ocupan de las microfinanzas (Luxemburgo, 14 a 16 de noviembre de 2012).

17. La Secretaría asistió a la Semana del derecho, la justicia y el desarrollo de 2012, encuentro anual en el que se examina la forma en que el derecho y la justicia contribuyen al desarrollo mediante la creación de oportunidades, la inclusividad y la equidad. Al encuentro asistieron funcionarios del Grupo del Banco Mundial, directivos de otras instituciones financieras internacionales, profesionales internacionales del ámbito del desarrollo, funcionarios de gobierno, abogados, jueces, estudiosos y representantes de la sociedad civil; la organización corrió a cargo de la Vicepresidencia Jurídica del Banco Mundial, los departamentos jurídicos de la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Además, esa semana se inauguró oficialmente el Foro Mundial sobre Derecho, Justicia y Desarrollo. Se señaló que se trataba de un foro de carácter permanente para el intercambio de conocimientos y la creación de vínculos entre los países en desarrollo, los centros de estudios, las organizaciones regionales e internacionales, las instituciones financieras internacionales, los gobiernos, los sistemas judiciales, el sector privado y las organizaciones cívicas con las investigaciones y las prácticas pertinentes⁷ (Washington, D.C., 10 a 14 de diciembre de 2012).

2. Contratación pública

18. A instancias de la Comisión y del Grupo de Trabajo I (Contratación Pública), la Secretaría ha establecido vínculos con otras organizaciones internacionales interesadas en la reforma de la contratación pública para fomentar la cooperación en lo que respecta a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública

⁷ Semana del derecho, la justicia y el desarrollo de 2012, nota conceptual. Puede consultarse en: http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTICE/214576-1340728175970/23321647/LJDWEEK_2012_Concept_Note.docx.

de 2011 y la Guía para la incorporación al derecho interno que la acompaña (2012). Los objetivos de esa cooperación son asegurar que los gobiernos y las organizaciones que emprendan esa reforma conozcan las consideraciones normativas que sustentan esos textos, de manera que se promuevan una comprensión a fondo y una utilización apropiada de la Ley Modelo a nivel regional y nacional. La Secretaría aplica un enfoque regional a esta cooperación, y se prevé llevar a cabo actividades con los bancos multilaterales de desarrollo en varias regiones, haciendo hincapié en la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción (en la cual la reforma de la contratación pública desempeña una función fundamental).

19. Con esa finalidad, la Secretaría ha participado, entre otras, en las siguientes actividades:

a) La reunión del Grupo Consultivo Internacional sobre la Contratación Pública del Banco Mundial, que asesora a esa entidad a efectos de un examen amplio de su política de contratación pública, su nuevo instrumento financiero llamado “Programa por Resultados”, su función de contratación pública en el contexto de la responsabilidad financiera pública y la necesidad de reforzar la gestión de los contratos (Washington, D.C. 4 y 5 de junio de 2012 y 12 y 13 de noviembre de 2012);

b) La segunda conferencia anual de la Unión Europea sobre la reforma de la contratación pública, organizada por *IBC Legal Conferences*, en que se abordaron las reformas de la contratación pública introducidas por la CNUDMI y los aspectos de esas reformas que concordaban con las propuestas de la Unión Europea o divergían de ellas. La Secretaría presentó una ponencia en la conferencia (Bruselas, 20 de septiembre de 2012);

c) El seminario sobre contratación pública y comercio organizado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en que se abordaron las propuestas de la Unión Europea sobre la reglamentación del acceso de terceros proveedores y contratistas al mercado de la contratación pública de la Unión, relativas a los principios de la participación internacional en licitaciones en el marco de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre esa cuestión (París, 7 de noviembre de 2012). La Secretaría presentó una ponencia en el seminario;

(d) El quinto período de sesiones del equipo de especialistas de la Comisión Económica para Europa (CEPE), durante el cual la Secretaría presentó la posible labor futura de la CNUDMI en el ámbito de las asociaciones entre los sectores público y privado, con miras a garantizar una coordinación apropiada de la comunidad de donantes a ese respecto (Ginebra (Suiza), 5 y 6 de febrero de 2013);

(e) La Reunión de la OCDE de profesionales destacados en materia de contratación pública y la labor en curso sobre los aspectos fundamentales de la actualización de la recomendación formulada por la OCDE sobre el fomento de la integridad en la contratación pública, cuyo objetivo es orientar a los responsables de adoptar decisiones sobre la forma de utilizar la convocatoria a licitaciones como función estratégica de los gobiernos (París, 11 y 12 de febrero de 2013). La Secretaría presentó una ponencia en la reunión; y

f) La reunión de los jefes de contratación pública de los bancos multilaterales de desarrollo⁸, en que la Secretaría presentó la posible labor futura de la CNUDMI en el ámbito de las asociaciones entre los sectores público y privado con miras a garantizar una coordinación apropiada de la comunidad de donantes a ese respecto (París, 14 de marzo de 2013).

3. Solución de controversias

20. La Secretaría participó en las siguientes actividades:

a) Labor consultiva relacionada con la publicación de la “Serie rosa” (“*Pink Series*”) de la UNCTAD sobre la transparencia en los acuerdos internacionales de inversión, titulada “*Transparency 2012*”, a fin de garantizar que se promoviera un enfoque congruente de la UNCTAD y la CNUDMI en el ámbito de la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado; y

b) Labor consultiva y de coordinación con el Grupo de trabajo del UNIDROIT sobre la utilización de los principios del UNIDROIT en las cláusulas compromisorias.

21. La Secretaría también organizó una reunión con representantes de instituciones arbitrales en relación con el establecimiento de un registro de la transparencia, en el marco del proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (Viena, 3 de diciembre de 2012)⁹.

4. Comercio electrónico

22. La Secretaría se ha ocupado especialmente de coordinarse con las instituciones internacionales y regionales que participan en la formulación de normas jurídicas en el ámbito del comercio electrónico, a fin de garantizar su compatibilidad con los textos y principios de la CNUDMI.

23. Entre las actividades¹⁰ figuraron las siguientes:

a) Coordinación con la Comisión Europea sobre su proyecto de reglamento relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (Bruselas, 5 de septiembre de 2012);

b) Coordinación con el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y el Comercio Electrónico (UN/CEFACT), sobre la revisión de la recomendación 14, relativa a la autenticación de documentos comerciales, y la preparación de la recomendación 36, sobre la interoperabilidad de la ventanilla única (Viena, 17 a 21 de septiembre de 2012);

⁸ En ella estuvieron representados los siguientes bancos: el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Islámico de Desarrollo.

⁹ Véase A/CN.9/WG.II/WP.177.

¹⁰ Las actividades de coordinación en el ámbito del comercio electrónico realizadas por el Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico se enumeran en el documento A/CN.9/775.

c) Participación en la 13ª reunión plenaria del Consejo de Asia y el Pacífico para la Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas (Teherán, 21 y 22 de noviembre de 2012);

d) Participación en la reunión organizada por el grupo de tareas *Identity Management Legal Task Force de la American Bar Association* (ABA), (Londres, 10 y 11 de diciembre de 2012); y

e) Participación en la labor del Grupo básico de expertos sobre el delito relacionado con la identidad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (Viena, 16 a 18 de enero de 2013).

5. Garantías reales

24. Se ha procurado coordinar con las organizaciones pertinentes a fin de impartir a los Estados una orientación integral y coherente en lo que respecta al régimen de las operaciones garantizadas.

25. Entre las actividades concretas de la Secretaría figuraron las siguientes:

a) Coordinación con el UNIDROIT para garantizar que el texto que prepara sobre la compensación global no se superponga ni se contraponga a los textos sobre garantías reales preparados por la CNUDMI (véase también el párrafo 6);

b) Coordinación con la Comisión Europea para asegurar que se aplicara un enfoque coordinado respecto de la ley aplicable a la eficacia frente a terceros de las cesiones de créditos; y

c) Coordinación con el Banco Mundial para preparar un conjunto común de principios sobre las operaciones garantizadas.

6. Insolvencia

26. La Secretaría participó en el tercer período de sesiones del grupo de trabajo del Banco Mundial sobre el tratamiento de la insolvencia de las personas físicas (Washington, D.C., 13 y 14 de diciembre de 2012). El grupo de trabajo se estableció bajo los auspicios del equipo de tareas del Banco Mundial sobre regímenes de insolvencia para determinar las políticas y los principios generales que sustentan los diferentes ordenamientos jurídicos que se han desarrollado para abordar eficazmente los riesgos derivados de la insolvencia de los consumidores y el sobreendeudamiento de las personas físicas en el contexto actual, así como para preparar un informe que sirviera de orientación sobre las características de un régimen de la insolvencia eficaz para las personas físicas y las posibilidades y dificultades surgidas en la elaboración de dicho régimen. El informe se terminó de redactar y se aprobó en el actual período de sesiones.

7. Fraude comercial

27. En cumplimiento de la solicitud de la Comisión (A/63/17, párr. 347, y A/64/17, párr. 354) relativa a la labor en materia de fraude comercial, la Secretaría ha seguido participando en el trabajo de la UNODC sobre la delincuencia económica y los delitos de falsificación de identidad. En particular, la Secretaría ha participado en el Grupo básico de expertos de la UNODC sobre el delito relacionado con la identidad, que se creó con el objeto de reunir periódicamente a representantes

de los gobiernos, entidades del sector privado, organizaciones internacionales y regionales y los círculos académicos para que sumaran sus experiencias, elaboraran estrategias, facilitaran nuevas investigaciones y acordaran medidas prácticas contra el delito relacionado con la identidad. La sexta y más reciente reunión del Grupo básico de expertos se celebró del 16 al 18 de enero de 2013 en Viena (véase también el párrafo 23 e)).

Tercera parte

ANEXOS

I. ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado

Acta resumida de la 958ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena, Viena, el lunes 8 de julio de 2013 a las 10.00 horas

[A/CN.9/SR.958]

Presidente interino: Sr. Sorieul (Secretario de la Comisión)

Presidente: Sr. Schöll (Suiza)

Más tarde: Sr. Moollan (Presidente del Grupo de Trabajo II) (Mauricio)

Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.

Apertura del período de sesiones

1. El Sr. **Sorieul** (Secretario de la Comisión) declara abierto el 46º período de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Elección de la Mesa

2. El Sr. **Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que corresponde al Grupo de los Estados de Europa Occidental y Otros Estados proponer un candidato para el cargo de Presidente. El Grupo ha comunicado a la Comisión su deseo de proponer la candidatura del Sr. Schöll (Suiza).

3. *Por aclamación, el Sr. Schöll (Suiza) queda elegido Presidente.*

4. *El Sr. Schöll (Suiza) ocupa la Presidencia.*

Aprobación del programa

5. El **Presidente** invita a la Comisión a aprobar el programa.

6. El Sr. **Caplan** (Estados Unidos de América) confía en que la Comisión no adopte decisión alguna con respecto a autorizar trabajos en el marco de proyectos actuales o futuros antes de examinar el tema 16 del programa.

7. El Sr. **Bellenger** (Francia) propone que el tema 16 se examine el lunes 22 de julio, y no al final del período de sesiones.

8. El Sr. **Sorieul** (Secretario de la Comisión) informa de que la secretaría ha programado oficiosamente el

examen del tema 16 para el miércoles 24 de julio por la mañana. No obstante, la fecha puede adelantarse si la Comisión lo desea.

9. El Sr. **Apter** (Israel) dice que los miembros de los diversos grupos de trabajo probablemente no estén presentes durante todo el período de sesiones. Por consiguiente, pregunta si, por ejemplo, los miembros del Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) podrían presentar sus opiniones sobre la labor futura, de manera informal, antes de que finalizara la segunda semana.

10. El **Presidente** dice que la sugerencia del representante de Israel está en consonancia con la práctica aplicada por la Comisión en años recientes.

11. *Queda aprobado el programa.*

Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación

a) **Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado** (A/CN.9/760, 765, 783 y 787 y Add.1, Add.2 y Add.3)

12. El Sr. **Sorieul** (Secretario de la Comisión) recuerda la costumbre de que el Presidente del Grupo de Trabajo II dirija las deliberaciones sobre cuestiones de arbitraje y conciliación. El Sr. Moollan, representante de Mauricio, ha presidido durante varios años las actuaciones del Grupo de Trabajo. El orador cree entender que la Comisión desea que siga haciéndolo en el período de sesiones en curso.

13. **El Presidente** invita al Sr. Moollan a ocupar la Presidencia.

14. *El Sr. Moollan, Presidente del Grupo de Trabajo II, ocupa la Presidencia.*

15. **El Presidente** dice que la Comisión espera aprobar el proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia a fines de la primera semana del período de sesiones. La preparación del texto ha resultado ser un proceso sumamente complejo, por lo que insta a la Comisión a que tenga en cuenta ese aspecto durante el examen final. Por otra parte, muchas delegaciones han estado dispuestas a transar sustancialmente, como se puede apreciar en los párrafos 75 a 78 del informe del Grupo de Trabajo II sobre su 58º período de sesiones, celebrado en febrero de 2013 (documento A/CN.9/765). En consecuencia, el orador confía en que no se reabra el debate sobre las cuestiones de fondo en el período de sesiones en curso de la Comisión.

16. El orador observa que en su 58º período de sesiones el Grupo de Trabajo expresó su opinión unánime de que la Comisión era la institución más cualificada para desempeñar la función de registro o archivo de la información publicada con arreglo al Reglamento sobre la Transparencia. El problema es, sin embargo, obtener fondos con ese fin. Desde que concluyó ese período de sesiones se ha venido alentando a los Estados a financiar esa iniciativa al margen del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, y algunos de ellos, en principio, han expresado su voluntad de hacerlo. La otra opción es dirigirse primero a la Sexta Comisión y después a la Quinta Comisión de la Asamblea General a fin de obtener recursos del presupuesto ordinario. Si la Comisión no puede cumplir esa función por razones financieras, hay dos instituciones que han accedido gentilmente a hacerlo, a saber, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

17. Sería útil que se pudiese llegar a un acuerdo antes de fines de esa semana sobre la conveniencia de que la Comisión desempeñase la función de registro. Si hubiese más Estados dispuestos a aportar los fondos necesarios, tal vez no habría que recurrir a la Asamblea General a efectos de utilizar recursos del presupuesto ordinario. También sería útil que la Comisión decidiera antes de fines de esa semana cuál de las dos instituciones que se ofrecieron sería la que cumpliría esa función si todo lo demás fracasara.

18. El Sr. **Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que la secretaría ha emprendido consultas con miras a obtener los fondos necesarios. Si bien hasta ese momento la

respuesta ha sido muy alentadora, aún dista mucho de ser satisfactoria. La idea de que la Comisión desempeñe la función de registro de información en el marco del Reglamento sobre la Transparencia ha tenido amplio eco en la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York. Si se necesitaran fondos extrapresupuestarios, habría algunas opciones, aunque es importante que un servicio tan esencial como la difusión de la información publicada tenga un alcance universal. Así pues, resulta lógico afirmar que la decisión más sensata es encomendar la función a la secretaría de la Comisión, en vez de subcontratarla con una organización externa. Si bien las dos organizaciones que han ofrecido sus servicios son muy respetables, ninguna de ellas goza de la universalidad que caracteriza a un órgano administrado por la Secretaría de las Naciones Unidas.

19. La Sra. **Kobayashi-Terada** (Japón) pregunta si las dos organizaciones que se ofrecieron han presentado propuestas concretas respecto de los servicios que están dispuestas a prestar.

20. **El Presidente** dice que las dos presentaron propuestas que se darán a conocer a todos los miembros de la Comisión.

21. El Sr. **Sorieul** (Secretario de la Comisión) comunica que la secretaría tiene dificultades, también por razones presupuestarias, para hacer traducir con rapidez los documentos de la Comisión a los seis idiomas oficiales. Aun cuando los documentos se presenten en los seis idiomas, los servicios de traducción de las Naciones Unidas deben revisarlos para asegurarse de la exactitud de las traducciones.

22. **El Presidente** invita a la Comisión a examinar el proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, que figura en el documento A/CN.9/783, artículo por artículo. Toda modificación que se decida introducir será incorporada a las versiones de los diferentes idiomas por un comité de redacción.

Proyecto de artículo 1 – Ámbito de aplicación

23. **El Presidente** hace referencia a la observación de la Secretaría que figura en el párrafo 6 del documento, acerca del reordenamiento de los párrafos del proyecto de artículo 1 según las cuestiones de que tratan. De no haber objeciones, entenderá que la Comisión acepta ese reordenamiento.

24. *Así queda acordado.*

25. El **Presidente** dice que en el proyecto de artículo 1, párrafos 1 y 2, queda reflejada la solución de avenencia alcanzada por el Grupo de Trabajo II, según la cual el Reglamento sobre la Transparencia formará parte del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y regirá los tratados aprobados después de que entre en vigor, salvo que las partes opten por no aplicarlo. Esa solución se recoge en el párrafo 1 del artículo. En el párrafo 2 se establece una norma de interpretación estricta, es decir, una regla o norma claramente definida según la cual el Reglamento únicamente se aplicará a los arbitrajes de la CNUDMI entablados en el marco de un tratado existente si las partes litigantes así lo deciden de común acuerdo.

26. El Grupo de Trabajo II convino desde el principio en que el Reglamento sobre la Transparencia debería poder aplicarse a todas las formas de arbitraje. Al respecto, se solía hacer referencia a las Reglas de la Asociación Internacional de Abogados sobre la Práctica de la Prueba en los Arbitrajes Internacionales. Al iniciarse un proceso arbitral, el tribunal y las partes suelen ponerse de acuerdo para invocar esas Reglas, ya sea en calidad de normas aplicables o como lineamientos. Habida cuenta de la importancia de que las diversas instituciones puedan gestionar los arbitrajes con arreglo a sus reglamentos vigentes, conjuntamente con el Reglamento sobre la Transparencia, surge el problema de hacer o no referencia concretamente en el proyecto de artículo 1 a la aplicación del Reglamento en ese contexto. En el párrafo 7 del documento A/CN.9/783 se invita a la Comisión a que examine si en el encabezamiento del párrafo 2 debería añadirse la frase siguiente entre corchetes: “[o [ii] los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados, en el marco de un tratado, con arreglo a otros reglamentos de arbitraje o con carácter especial]”. A juicio del orador, ese no es el lugar apropiado para mencionar esa cuestión, si lo que se desea es lograr un equilibrio. En el párrafo 2 se establece una norma de interpretación estricta con respecto a los arbitrajes de la CNUDMI. Si se añadiera a ese párrafo el texto que figura entre corchetes, la Comisión estaría creando una norma de interpretación estricta para otras instituciones.

27. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) dice que añadir el texto propuesto serviría para aclarar la cuestión, ya que, de esa manera, todas las instituciones serían conscientes de que podrían aplicar el Reglamento si lo desearan. Eso también estaría en consonancia con el mandato del Grupo de Trabajo de crear una norma de transparencia para promover el arbitraje en todas las circunstancias.

28. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) opina que cabe aclarar la cuestión porque guarda relación con el principio de la autonomía de las partes, es decir, que el Reglamento únicamente será aplicable si las partes litigantes o las partes en un tratado convienen en que se aplique.

29. El **Sr. Agrawal** (India) está de acuerdo en que debe dejarse al arbitrio de las partes contratantes decidir acerca de la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia a los arbitrajes.

30. El **Sr. Apter** (Israel) expresa apoyo a la inserción de la nueva frase propuesta en el párrafo 2, tal vez con algunas modificaciones, ya que en ella se refleja la solución de avenencia alcanzada por el Grupo de Trabajo, que es de carácter general. Si todos los miembros de la Comisión están de acuerdo con ese criterio de interpretación estricta, habrá que aclarar que este regirá siempre que las partes en los arbitrajes entre inversionistas y Estados acepten el Reglamento sobre la Transparencia, que tiene un estatuto universal.

31. El **Presidente** dice que el hecho de insertar la nueva frase seguramente conlleva la aplicación universal del criterio de interpretación estricta. Debería hacerse una distinción entre el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y otros reglamentos cuando se tratase de la aplicación de normas de transparencia. En el proyecto de artículo 1 se crea un vínculo entre el Reglamento sobre la Transparencia y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI al modificarse el artículo 1 de este último. No obstante, no existe un vínculo de esa índole con respecto a otros reglamentos, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

32. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) se refiere a la propuesta formulada por su país en sus observaciones sobre el proyecto de reglamento (A/CN.9/787), a saber, añadir al proyecto de artículo 1 el siguiente nuevo párrafo 9: “El presente Reglamento podrá aplicarse a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados con arreglo a otros reglamentos de arbitraje cuando así lo permita la institución pertinente, o en procesos de carácter especial”.

33. El **Presidente** expresa reservas acerca de la frase “cuando así lo permita la institución pertinente”, en virtud de la cual las instituciones de todo el mundo estarían obligadas a declarar si están o no dispuestas a aplicar el Reglamento.

34. El **Sr. Lavranos** (Observador de los Países Bajos) prefiere que se conserve el margen que deja la frase, ya que no cabe confiar en que los reglamentos de todas las instituciones sean plenamente compatibles con el Reglamento sobre la Transparencia.
35. La **Sra. Kobayashi-Terada** (Japón) apoya la propuesta del Presidente de que se suprima la frase.
36. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) conviene en que sería preferible suprimir la frase, ya que solo serviría para desatar más debates molestos sobre cada una de las disposiciones.
37. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) dice que la formulación del nuevo párrafo propuesto es algo ambigua. Debería aclararse que las partes litigantes o las partes en el tratado tendrían que ponerse de acuerdo en que se aplicara el Reglamento sobre la Transparencia.
38. El **Sr. Kordač** (Observador de la República Checa) dice que el párrafo propuesto no constituye realmente una regla desde el punto de vista técnico. En consecuencia, podría ser preferible incorporarlo a la decisión de la Comisión sobre la aprobación del Reglamento o en su recomendación acerca de la aplicación de este.
39. El **Presidente** invita a los representantes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y la Corte Permanente de Arbitraje a que formulen observaciones acerca de la posibilidad de que se acepte el párrafo propuesto si se suprime la frase “cuando así lo permita la institución pertinente”.
40. La **Sra. Kinnear** (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) dice que su institución estaría dispuesta a aplicar el Reglamento sobre la Transparencia si las partes litigantes así lo desearan, o si el Estado de origen del inversionista y el Estado demandado hubiesen convenido en que se aplicara.
41. El **Sr. Daly** (Corte Permanente de Arbitraje) dice que no hay ninguna norma procesal de la Corte que entre en conflicto con el proyecto de reglamento sobre la transparencia de la manera en que está formulado en esos momentos. Por consiguiente, la Corte no tendría reparo alguno en aplicar el Reglamento en sus arbitrajes.
42. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) considera que el nuevo párrafo propuesto no afectaría al principio de la autonomía de las partes.
43. El **Presidente** cree entender que la Comisión desea aprobar el proyecto de párrafo 9 propuesto por los Estados Unidos, siempre y cuando se suprima la frase “cuando así lo permita la institución pertinente”, y que también desea que se suprima la frase que figura entre corchetes en el proyecto de párrafo 2.
44. *Así queda acordado.*
45. El **Presidente** se refiere a la propuesta que figura en el párrafo 8 del documento A/CN.9/783 en el sentido de aclarar en una segunda nota al pie del artículo 1 que toda referencia que se haga en el Reglamento a una “Parte en el tratado” o un “Estado” se aplica por igual a las organizaciones regionales de integración económica.
46. La **Sra. Kobayashi-Terada** (Japón) se refiere a la observación formulada por su país en el documento A/CN.9/787/Add.1/Corr.1, en que propuso una versión revisada de la primera nota de pie de página a fin de que el Reglamento sobre la Transparencia también rigiera los acuerdos internacionales en que son partes Hong Kong y Macao. Si se aprueba la segunda nota, la oradora propone que se le añada una referencia a “todo territorio autorizado por un Estado a concertar tratados”.
47. La **Sra. Liang Danni** (China) dice que, si bien su país ejerce soberanía sobre Hong Kong y Macao, los dos territorios están facultados, en virtud de la norma constitucional, para decidir por sí mismos si van a aplicar el Reglamento sobre la Transparencia.
48. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América), remitiéndose a la definición de “tratado” que figura en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, propone que en la primera nota se inserte una frase del siguiente tenor: “todo acuerdo regido por normas de derecho internacional que se haya concertado entre dos o más partes en esos tratados”.
49. El **Sr. Brown** (Unión Europea) dice que, si las modificaciones propuestas conllevan la supresión de la segunda nota, cabe recordar que el propósito de esta es aclarar que, cuando en el proyecto de reglamento se usa el término “Estado”, las disposiciones pertinentes también se aplican a las organizaciones regionales de integración económica y tal vez a otras entidades no estatales. En consecuencia, considera que la segunda nota debe conservarse.
50. El **Presidente** sugiere que en las dos notas se utilice una formulación neutral como la propuesta por el representante de los Estados Unidos. Podría presentarse el texto exacto a la Comisión tras la pausa para consultas que se anunciará en breve.
51. *Así queda acordado.*
52. El **Presidente** hace referencia al párrafo 9 del documento A/CN.9/783, relativo al apartado 3 b)

del proyecto de artículo 1, que se ha reformulado a fin de conceder cierto grado de flexibilidad al tribunal arbitral para que adapte el Reglamento si así lo exigen las circunstancias del procedimiento en cuestión. Se sugirió que se modificara la última frase, “sin menoscabar el objetivo de transparencia del Reglamento”, sustituyéndola por la frase “velando por cumplir el objetivo de transparencia del Reglamento”.

53. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) dice que la frase final tiene por objeto hacer que los tribunales arbitrales comprendan el alcance de sus facultades. En el documento A/CN.9/787/Add.1 el Canadá propuso el siguiente texto: “pero solo si esa adaptación es compatible con el objetivo de transparencia”.

54. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) propone como variante la frase “y se logre el objetivo de transparencia del Reglamento”.

55. El **Presidente** cree entender que la Comisión desea aprobar el apartado 3 b) con la modificación propuesta por el representante de los Estados Unidos.

56. *Así queda acordado.*

57. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) opina que, en el apartado 2 b) del proyecto de artículo 1, la expresión “el Estado de origen del inversionista” resulta algo inapropiada en el contexto de normas procesales o de tratados de inversión. Habida cuenta de que eso podría dar lugar a objeciones de carácter jurisdiccional, propone que la expresión “el Estado de origen del inversionista y el Estado demandado” se sustituyan por la expresión “las partes pertinentes”.

58. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) dice que el Grupo de Trabajo II ya modificó “las partes pertinentes” por alguna razón que no puede recordar. Solicita tiempo para examinar esa cuestión durante la pausa que se hará para celebrar consultas.

59. *Así queda acordado.*

60. El **Presidente** invita a la Comisión a que considere cuál sería la fecha más apropiada para la entrada en vigor del Reglamento sobre la Transparencia. Hay que tener en cuenta que este habrá de traducirse a los seis idiomas oficiales. También habría que dirigirse a las Comisiones Sexta y Quinta a efectos de determinar si se podrían obtener los fondos necesarios para que la Comisión se encargara de la función de archivo de la información publicada. Por lo tanto, en opinión del orador, lo más conveniente sería programarla para el primer semestre de 2014.

61. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) conviene en que, si la Comisión decide recabar fondos para poder desempeñar la función de registro, el Reglamento entre en vigor a principios de 2014. De lo contrario, podría elegirse una fecha anterior.

62. El **Sr. Apter** (Israel) propone que, en vez de fijar fecha para la entrada en vigor, la Comisión prevea la entrada en vigor gradual de diversas disposiciones lo antes posible. Tal vez puede indicar en sus recomendaciones sobre la aplicación del Reglamento que las normas relativas al registro entrarán en vigor una vez que este se haya establecido.

63. El **Presidente** sugiere que la propuesta del representante de Israel se examine conjuntamente con los representantes de las diversas instituciones más adelante durante esa semana, antes de que se apruebe el proyecto de reglamento. Para ese entonces también se habrá aclarado la situación con respecto a los fondos extrapresupuestarios.

Se suspende la sesión a las 11.50 horas y se reanuda a las 12.20 horas.

64. El **Presidente** dice que el examen de las notas que figurarán al pie del proyecto de artículo 1, párrafo 1, se aplazará hasta la sesión siguiente.

65. El orador invita a la representante de Suiza a presentar su propuesta en relación con el apartado 2 b).

66. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) propone el siguiente texto: “las Partes en el tratado o, en el caso de un tratado multilateral, el Estado del demandante y el Estado demandado”. Es inaceptable que se haga referencia a “las partes pertinentes” porque no quedaría claro, por ejemplo, con arreglo al Tratado sobre la Carta de la Energía, si la parte responsable sería la Unión Europea o el Estado que hubiera adoptado determinada medida. Tampoco puede aceptarse la referencia al “Estado de origen del inversionista” debido a las controversias a que daría lugar con respecto a la jurisdicción.

67. El **Presidente** cree entender que la Comisión desea aprobar el apartado 2 b) con la modificación propuesta por la representante de Suiza.

68. *Así queda acordado.*

69. El **Presidente** dice que, durante la pausa que se hizo para celebrar consultas algunos miembros de la Comisión expresaron reservas respecto de la versión enmendada del apartado 3 b). En consecuencia, queda revocada la decisión de aprobarla y se invita a la representante de Suiza a que presente una modificación en nombre de los miembros en cuestión.

70. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) propone el siguiente texto: “pero solo si esa adaptación es compatible con el objetivo de transparencia del Reglamento”. Esa frase es igual, en español, a la propuesta por el Canadá, aunque en la versión inglesa se ha suprimido la palabra “*achieving*”.

71. **El Presidente** dice que la modificación propuesta se examinará en la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (continuación)

Acta resumida de la 959ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena, Viena, el lunes 8 de julio de 2013 a las 14.00 horas

[A/CN.9/SR.959]

Presidente interino: Sr. Moollan (Presidente del Grupo de Trabajo II) (Mauricio)

Se declara abierta la sesión a las 14.10 horas.

Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación

a) Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (continuación) (A/CN.9/760, 765, 783 y 787 y Add.1, Add.1/Corr.1, Add.2 y Add.3)

Proyecto de artículo 1 – Ámbito de aplicación (continuación)

1. **El Presidente** recuerda a la Comisión la propuesta de la representante de Suiza de que en el proyecto de artículo 1, apartado 3 b), se sustituyera la expresión “sin menoscabar el objetivo de transparencia del Reglamento” por la frase siguiente: “pero solo si esa adaptación es coherente con el objetivo de transparencia del Reglamento”. Observa que los representantes del Canadá, los Estados Unidos, Francia, el Japón, Singapur y Tailandia hicieron suya la modificación propuesta. De no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar la modificación.

2. *Así queda acordado.*

3. El **Sr. Agrawal** (India) propone que, al comienzo del apartado, después de “tribunal arbitral”, se inserte la expresión “en consulta con las partes litigantes”.

4. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) considera preferible que esa expresión se añada en otro lugar del apartado, ya que no sería apropiado afirmar que el tribunal arbitral, en consulta con las partes litigantes, “estará facultado para” adoptar ciertas medidas. También cabría comprobar si el hecho de consultar con las partes litigantes se menciona en todos los contextos. Si solo se menciona en algunos casos, puede haber malentendidos.

5. **El Presidente** sugiere que la secretaría compruebe ese importante aspecto de armonización antes de la siguiente sesión.

6. El **Sr. Apter** (Israel) propone que se inserte un artículo a efectos de disponer que en los casos en que el tribunal arbitral goce de facultades discrecionales, necesariamente deberá celebrar consultas con las partes litigantes al aplicar el Reglamento sobre la Transparencia.

7. **El Presidente** sugiere que se adopte una decisión al respecto también en la siguiente sesión.

8. La otra cuestión pendiente con respecto al proyecto de artículo 1 son las notas de pie de página correspondientes al párrafo 1. Después podrá aprobarse el proyecto de artículo 1 en su conjunto.

Proyecto de artículo 2 – Publicación de información al inicio del procedimiento arbitral

9. **El Presidente** se refiere a la observación formulada por el Japón en el documento A/CN.9/787/Add.1 en relación con el proyecto de artículo 2. El Japón señala que, en su formulación actual, el proyecto de reglamento no abarca las situaciones en que una de las partes litigantes (normalmente, el demandado) cuestione la aplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia, y pregunta si ese asunto se abordará en directrices prácticas para el archivo.

10. La **Sra. Kobayashi-Terada** (Japón) propone abordar la cuestión en las directrices para el archivo o añadir al Reglamento el nuevo párrafo siguiente: “En caso de controversia con respecto a la posibilidad de aplicar el Reglamento sobre la Transparencia al arbitraje en cuestión, el archivo deberá poner la información mencionada anteriormente a disposición del público una vez que el tribunal arbitral haya decidido que se aplicará el Reglamento”.

11. **El Presidente** considera necesario que la Comisión adopte una decisión de principio con respecto a qué clase de información debería hacerse pública y en qué etapa del procedimiento. Es esencial establecer un equilibrio entre los proyectos de artículo 2 y 3 en lo que concierne a la publicación de documentos. Hay dos posibles modos de solucionar las controversias de índole jurisdiccional que surjan en relación con el proyecto de artículo 2. Se puede

concluir que la información es tan limitada que no reviste gran importancia. Siempre y cuando el registro reciba lo que pueda considerarse una notificación del arbitraje, en la que se indique que el Reglamento sobre la Transparencia es aplicable, podrá procederse a la publicación de esa información. La otra opción es proceder como se sugiere en el nuevo párrafo propuesto por el Japón, es decir, exigir que el tribunal arbitral adopte una decisión al respecto. Sin embargo, en ese caso se otorgaría a los demandados un derecho unilateral a aplazar la publicación de información hasta que el tribunal se hubiera constituido.

12. El orador pregunta a la representante del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) cómo procede el Centro en esas circunstancias.

13. La **Sra. Kinnear** (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) dice que el CIADI debe publicar en su sitio web lo que podría denominarse información de referencia, entre otras cosas, los nombres de las partes litigantes, pero solo una vez que el caso se ha inscripto en el registro. No obstante, solo se inscribe un caso cuando no queda manifiestamente al margen de la competencia del CIADI. En consecuencia, en el Reglamento del Centro ya se ha previsto una prueba relativa a ese asunto. Aun cuando el caso esté inscripto, pueden plantearse controversias con respecto a la competencia, la nacionalidad y otras cuestiones, si bien, en cualquier caso, se publicará toda la información pertinente en el sitio web.

14. **El Presidente** señala que, por lo tanto, en el caso del CIADI existe una válvula de escape limitada.

15. El **Sr. Daly** (Corte Permanente de Arbitraje) dice que la función del Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje en materia de designación de autoridades nominadoras constituye una válvula de escape en relación con el régimen de la CNUDMI. En la mayoría de los tratados entre inversionistas y Estados no se prevé una autoridad nominadora. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre una autoridad cuando se suscita una controversia, piden al Secretario General que designe a una autoridad nominadora. Sin embargo, los Estados pueden oponerse a toda medida de esa clase que adopte la Corte en respuesta a algunas solicitudes de los inversionistas. Pueden alegar que el arbitraje se instituyó indebidamente y que hay cuestiones jurisdiccionales. En ese caso, la Corte puede realizar un examen a primera vista de los documentos presentados y decidir el modo de proceder. Si no hubiera una base para el reconocimiento de la competencia, el caso se suspendería y no se constituiría un tribunal.

16. Con arreglo a la actual propuesta relativa al Reglamento sobre la Transparencia, se publicaría una cantidad limitada de información antes de que se constituyera un tribunal arbitral y sin que hubiese pruebas prima facie de un acuerdo de arbitraje. En opinión del orador, algunos Estados podrían oponerse a ese procedimiento. En una carta de fecha 29 de mayo de 2013 dirigida a la secretaria de la Comisión, la Corte advirtió acerca de la posibilidad de que se presentaran demandas arbitrarias infundadas y propuso que se añadiera el siguiente texto al proyecto de artículo 2: “El archivo podrá remitir toda cuestión relativa a la publicación de la información prevista en el artículo 2 al tribunal arbitral, una vez que se haya constituido”.

17. **El Presidente** dice que, presumiblemente, el encargado del archivo solo tomaría esas medidas discrecionales cuando tuviese serias dudas acerca del procedimiento de publicación.

18. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) advierte que no hay que complicar indebidamente la cuestión. De resultas de deliberaciones anteriores se decidió restringir el material que publicaría automáticamente el registro al comienzo de un procedimiento de arbitraje a los nombres de las partes, los sectores interesados y el tratado pertinente. Así pues, no hay necesidad de que el registro adopte ninguna medida de carácter discrecional. La información más delicada se publicaría una vez constituido el tribunal arbitral.

19. La **Sra. Kobayashi-Terada** (Japón) dice que, en términos generales, coincide con la representante de Suiza. No obstante, como puede haber casos en que las partes cuestionen la aplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia, tal vez sería conveniente elaborar directrices para el registro, o incorporar el texto propuesto por el representante de la Corte Permanente de Arbitraje en el proyecto de artículo 2. Al respecto, la delegación del Japón mantiene una posición flexible.

20. **El Presidente** sugiere que en los antecedentes de la redacción se deje constancia de la manera en que la Comisión entiende que el encargado del registro debe actuar, a saber, sin ejercer discrecionalidad al comienzo de las actuaciones arbitrales. Toda alegación de que haya actuado ultra vires podrá abordarse en virtud de una cláusula de descargo de responsabilidad. De no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el proyecto de artículo 2 sin cambios.

21. *Queda aprobado el artículo 2.*

Proyecto de artículo 3 – Publicación de documentos

22. **El Presidente** hace referencia al párrafo 15 del documento A/CN.9/783, en el que se invita a la Comisión a decidir si se debería conservar en el texto la última oración del párrafo 2, que figura entre corchetes. La frase en cuestión es la siguiente: “Por ejemplo, cabe la posibilidad de que esos documentos se pongan a disposición del público en un sitio determinado”.

23. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) dice que la oración es innecesaria desde el punto de vista jurídico, ya que únicamente se da un ejemplo de cómo pueden facilitarse los documentos. Con todo, el ejemplo podría ofrecer cierta orientación al tribunal arbitral en cuanto a la forma en que pueden hacerse públicos los medios probatorios y documentos de otra índole que no estén previstos en los párrafos 1 y 2 del artículo.

24. La **Sra. Escobar** (El Salvador) propone que la oración se inserte en una nota de pie de página y no en el texto del párrafo 3.

25. **El Presidente** dice que no es costumbre insertar notas al pie de normas sustantivas. De no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea suprimir los corchetes y conservar la oración en el párrafo 3.

26. *Así queda acordado.*

27. **El Presidente** señala a la atención de la Comisión el párrafo 16 del documento A/CN.9/783, en que se invita a esta a examinar si en el párrafo 5 del proyecto de artículo 3, las palabras “secundarios que conlleve la facilitación del acceso del público a dichos documentos” aclaran lo suficiente que los terceros no tendrán que sufragar los gastos administrativos relacionados con la publicación, entre ellos, los relativos a incorporar los documentos al sitio web del registro.

28. La **Sra. Escobar** (El Salvador), se remite a las observaciones formuladas por su país en el documento A/CN.9/787/Add.1 y propone que se añada el texto siguiente a la expresión “a disposición del público”: “como los de fotocopiado o envío de los documentos, no así los gastos administrativos relacionados con la publicación, como los relativos a cargar los documentos en el sitio web del registro”.

29. El **Sr. Brown** (Unión Europea) propone que se sustituya la expresión “a disposición del público” por “a disposición de esas personas” y que en la versión propuesta por la representante de El Salvador se sustituya “los gastos administrativos relacionados con la publicación” por “los gastos administrativos que conlleve facilitar el acceso del público a esos documentos”.

30. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) apoya la primera modificación propuesta por el representante de la Unión Europea. Propone que el texto de la última frase sea: “los gastos administrativos que conlleve facilitar el acceso del público a esos documentos por medio del registro”.

31. El **Sr. Brown** (Unión Europea) prefiere “archivo” a “registro”.

32. **El Presidente** sugiere que se conserven las palabras “a esas personas” después de “fotocopiado o envío de los documentos”.

33. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) propone simplificar el texto diciendo “sufragarán los gastos que conlleve facilitar el acceso de esas personas a los documentos” y suprimiendo “los gastos administrativos secundarios que conlleve”.

34. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) recuerda que se utilizó la expresión “gastos administrativos” a fin de excluir, por ejemplo, los gastos relacionados con los servicios letrados necesarios para examinar los documentos a efectos de expurgarlos.

35. El **Sr. Lavranos** (Observador de los Países Bajos), el **Sr. Möller** (Observador de Finlandia) y el **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) apoyan la propuesta de la representante de Suiza, siempre y cuando se conserve la palabra “administrativos”.

36. El **Sr. Jacquet** (Francia) expresa reservas debido a la posibilidad de dar a entender que los gastos serán sufragados automáticamente por las personas a que se hace referencia en el párrafo 5. Podría ser más sencillo y más compatible con el espíritu del texto sustituir “sufragarán” ciertos gastos por “sufragarán únicamente” los gastos en cuestión.

37. **El Presidente** se refiere a la enmienda propuesta por los Estados Unidos en el documento A/CN.9/787 y su observación en el sentido de que debería suprimirse la remisión al párrafo 2 en el párrafo 5.

38. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) dice que la publicación a cargo del registro en cumplimiento del párrafo 2 es automática. Solo en el caso del párrafo 3 el encargado del registro tiene facultades discrecionales para facilitar determinado material.

39. **El Presidente** observa que los documentos se comunican automáticamente con arreglo a los párrafos 1 y 2. En el párrafo 4 se indica la forma en que eso ocurre, a saber, por medio de una comunicación del tribunal arbitral al archivo, tras lo cual este último publicaría los documentos, presumiblemente en su sitio web. El párrafo 3

entra en una categoría diferente, ya que se refiere a la adopción de medidas discrecionales por parte del tribunal arbitral, entre otras cosas, con respecto a proporcionar o no el material y de qué manera. El tribunal podría decidir hacerlo por medio del archivo o, por ejemplo, en un sitio determinado. En todo caso, el orador considera que la remisión al párrafo 2 debe suprimirse del párrafo 5.

40. El orador da lectura al texto del párrafo 5 con la modificación introducida: “Las personas que, sin ser partes litigantes, reciban acceso a documentos con arreglo a lo establecido en el párrafo 3 sufragarán los gastos administrativos que conlleve facilitar el acceso de esas personas a los documentos, como los de fotocopiado o envío de los documentos a esas personas, pero no los gastos administrativos que conlleve facilitar el acceso del público a esos documentos por medio del archivo”.

41. El **Sr. Apter** (Israel) opina que el significado de la primera referencia a los “gastos administrativos” no queda claro. Si un tercero desea consultar esos documentos, lo normal es que sufrague los gastos que entrañe obtenerlos, aunque no sean específicamente administrativos. No obstante, los inversionistas a veces son empresas pequeñas y la imposición de costos adicionales podría causar problemas. Si se suprimiera la palabra “administrativos”, el tribunal arbitral tendría más margen de maniobra. Por lo tanto, el orador apoya la formulación propuesta por la representante de Suiza.

42. **El Presidente** dice que la supresión del término “administrativos” constituiría una modificación de fondo. Recuerda que ya hubo un considerable debate a fondo sobre esa cuestión.

43. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) expresa preocupación por las consecuencias financieras de la publicación de esos documentos. Por ejemplo, en el caso de *Cargill, Incorporated c. United Mexican States*, las partes necesitaron 17 meses para llegar a un acuerdo sobre la formulación del laudo arbitral definitivo. Singapur opina que en el Reglamento sobre la Transparencia deben compaginarse los distintos intereses: los de los Estados, los inversionistas y la sociedad civil. De las consultas oficiosas con los profesionales se desprende que el Reglamento podría aumentar los costos del arbitraje del 20% al 50% en concepto de asesoramiento letrado con fines de expurgación.

44. **El Presidente** recuerda que varias delegaciones plantearon la misma cuestión durante las deliberaciones anteriores. Por esa razón se decidió incluir una norma de publicación automática de una categoría restringida de documentos en el proyecto de artículo 3, párrafos 1 y 2, y

prever en el párrafo 3 una publicación más amplia de medios probatorios que pudiesen perturbar más las actuaciones. También se decidió que se permitiera al tribunal arbitral actuar con discrecionalidad al respecto. Además, en el proyecto de artículo 1, párrafo 4, se exige que el tribunal tenga en cuenta los intereses del público y los de las partes litigantes y que garantice el derecho a la justa resolución de la controversia.

45. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) solicita a los miembros de la Comisión con experiencia en procedimientos de arbitraje que formulen comentarios acerca del volumen de los documentos que pueden estar comprendidos en el ámbito del párrafo 2.

46. **El Presidente** dice que en procedimientos de arbitraje relativamente importantes, el volumen medio de documentos sería de unos pocos cientos de páginas. La declaración de un testigo normalmente puede ocupar de 40 a 50 páginas y un informe pericial detallado, tal vez de 50 a 100 páginas. En un expediente normal habrá cinco o seis de cada uno de ellos. Como los documentos probatorios pueden ser muy voluminosos, el tribunal arbitral debería estar en condiciones de decidir a su arbitrio si y cómo deberían facilitarse, especialmente si el hecho de publicarlos redundara en un retraso considerable de las actuaciones.

47. De no haber objeciones, el orador entenderá que la Comisión desea aprobar el proyecto de artículo 3 con las modificaciones introducidas.

48. *Queda aprobado el artículo 3.*

Proyecto de artículo 4 – Escritos presentados por terceros

49. **El Presidente** invita a formular observaciones sobre el proyecto de artículo 4.

50. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) propone que en el encabezamiento del párrafo 2 se supriman las palabras “que pueda haber” después de “el límite de páginas”, ya que se da a entender que el tribunal arbitral únicamente podría determinar el límite de páginas una vez dictada la primera providencia del procedimiento.

51. Los Estados Unidos también tienen reservas con respecto a la referencia a “la financiación de aproximadamente el 20%” que figura al final del apartado 2 c). Con miras a indicar que ese porcentaje es meramente ilustrativo, proponen la siguiente variante: “por el tercero con arreglo al presente artículo (por ejemplo, la financiación de aproximadamente el 20% del total de sus operaciones anualmente)”.

52. **El Presidente** sugiere que en la versión inglesa se suprima la palabra “such” del encabezamiento del párrafo 2. La versión enmendada de la frase sería la siguiente: “y ajustada al límite de páginas que haya determinado el tribunal arbitral”.

53. *Así queda acordado.*

54. **El Presidente** dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión también apoya la segunda enmienda propuesta por el representante de los Estados Unidos.

55. *Así queda acordado.*

56. *Queda aprobado el artículo 4 en su forma enmendada.*

Se suspende la sesión a las 15.25 horas y se reanuda a las 15.55 horas.

57. **El Presidente** invita a la Comisión a reanudar el examen de las notas de pie de página relativas al proyecto de artículo 1.

58. **El Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) propone sustituir las palabras “todo acuerdo concertado entre Estados u organizaciones regionales de integración económica, incluidos acuerdos de libre comercio” por “todo tratado, incluidos los denominados acuerdos de libre comercio”.

59. También propone la siguiente versión enmendada de la segunda nota de pie de página: “A los fines del Reglamento sobre la Transparencia, toda referencia a una ‘parte en el tratado’ o a un ‘Estado’ se aplica igualmente, por ejemplo, a una organización regional de integración económica que sea parte en el tratado”.

60. **El Sr. Brown** (Unión Europea) indica que su delegación necesita tiempo para confirmar que el nuevo enunciado es aceptable.

61. La **Sra. Pólit** (Ecuador), con referencia a la primera nota de pie de página, opina que no queda claro si la palabra “tratado”, aunque es un término genérico, abarca todos los tipos de acuerdos y convenciones.

62. **El Presidente** propone que el texto de la primera nota sea el siguiente: “A los fines del Reglamento sobre la Transparencia, por ‘tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas’ se entenderá, en sentido amplio, todo tratado bilateral o multilateral que contenga disposiciones sobre la protección de las inversiones o los inversionistas y el derecho de los inversionistas a recurrir al arbitraje contra las partes en el tratado, incluidos los

tratados comúnmente denominados acuerdos de libre comercio, acuerdos de integración económica, acuerdos marco o de cooperación en materia de comercio e inversiones o tratados bilaterales de inversión”.

63. La **Sra. Pólit** (Ecuador) dice que la nota se refiere a un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas y pregunta sobre la situación de los países que son receptores de inversiones.

64. **El Presidente** dice que el único propósito de la nota es aclarar el alcance del Reglamento. La delegada del Ecuador ha planteado una cuestión de fondo válida que debería estudiar el tribunal competente.

65. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) observa que en el proyecto de artículo 1, párrafo 1, por “tratado” se entiende un tratado que prevea la protección de las inversiones o los inversionistas y destaca la importancia de utilizar el término de manera sistemática en todo el Reglamento.

66. **El Presidente** dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar las dos notas de pie de página con las modificaciones introducidas.

67. *Así queda acordado.*

Proyecto de artículo 5 – Escritos presentados por partes en el tratado no litigantes

68. **El Presidente** se refiere al párrafo 20 del documento A/CN.9/783, en que se indica que el Grupo de Trabajo convino en que el tribunal arbitral debería aceptar los escritos presentados por partes en un tratado no litigantes en relación con la interpretación de dicho tratado, siempre y cuando esos escritos no perturbaran ni dificultaran innecesariamente el proceso arbitral y no causaran ningún perjuicio indebido a ninguna de las partes litigantes.

69. **El Sr. Spelliscy** (Canadá), con referencia a la utilización de las palabras “aceptará” y “aceptar” en el proyecto de artículo 5, párrafos 1 y 2, observa que en el artículo 4, en un contexto similar, se utiliza la palabra “permitir”. Su delegación propone que se emplee el mismo término en el proyecto de artículo 5 con fines de armonización.

70. *Así queda acordado.*

71. **El Sr. Lee Jae Min** (República de Corea) observa que en el proyecto de artículo 5, párrafos 4 y 5, se utilizan las palabras “los escritos” y que en el artículo 4, párrafos 5 y 6, se dice “el escrito” y propone que se utilicen las palabras “los escritos” en los dos artículos.

72. *Así queda acordado.*

73. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) propone que en la segunda oración del párrafo 2 del proyecto de artículo 5 se sustituya la frase “En el ejercicio de sus facultades discrecionales en cuanto a aceptar o no tales escritos” por la frase “Para determinar si se permite la presentación de esos escritos”, a fin de compatibilizar la formulación con la del artículo 4, párrafo 3.

74. El **Presidente** sugiere armonizar el texto del artículo 4 con el proyecto de artículo 5, ya que entonces quedaría claro que en ambos casos se están invocando las disposiciones del artículo 1, párrafo 4.

75. El **Sr. Magraw** (*Center for International Environmental Law*) dice que en el artículo 4 se ha usado la expresión “para determinar si se permite” porque en el párrafo 3 de ese artículo se enumeran varios criterios especiales que no figuran en el artículo 1. Por consiguiente, considera que debe conservarse el enunciado original.

76. El **Sr. Kordač** (Observador de la República Checa) está de acuerdo en que se conserve el texto original del artículo 4.

77. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) pide que la adopción de la decisión correspondiente se aplaze hasta la sesión siguiente.

78. *Así queda acordado.*

79. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) dice que, si bien en el proyecto de artículo 5 se incorporaron ciertas salvaguardias, su delegación considera que no se ha podido lograr el equilibrio necesario. En particular, si se admite que las partes en un tratado que no son litigantes intervengan en cuestiones distintas de la interpretación del tratado, el Estado puede verse obligado a responder no solo a las reclamaciones presentadas por los inversionistas, sino también al ejercicio de la protección diplomática.

80. La **Sra. Esnarriaga Arantes Barbosa** (Brasil), la **Sra. Le Duc Hanh** (Observadora de Viet Nam) y el **Sr. Yuprasert** (Tailandia) hacen suya la observación formulada por el representante de Singapur.

81. La **Sra. Pólit** (Ecuador) también se suma a la observación del representante de Singapur. Añade que en el proyecto de artículo 5 no se establece el debido equilibrio entre los inversionistas y los Estados receptores de inversiones.

82. El **Sr. Hirsch** (Argentina), tras hacer suya la observación del representante de Singapur, pide más tiempo para examinar ese aspecto del proyecto de artículo 5.

83. *Así queda acordado.*

Proyecto de artículo 6 – Audiencias

84. El **Presidente** se refiere a la observación que figura en el párrafo 22 del documento A/CN.9/783 en el sentido de que el Grupo de Trabajo expresó oficialmente su apoyo unánime a la propuesta de transacción revisada, que abarca el proyecto de artículo 6.

85. El **Sr. Lebedev** (Federación de Rusia) observa que, con arreglo al proyecto de artículo 6, párrafo 1, las audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales serán públicas, a reserva de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3. Habría que determinar, sin embargo, si las audiencias podrían celebrarse en privado cuando ambas partes litigantes así lo pactaran. El orador desea que se confirme que la formulación actual del proyecto de artículo no excluye esa posibilidad.

86. El **Presidente** recuerda que esa posibilidad fue objeto de extensas deliberaciones y se descartó como parte de la solución de transacción. Al respecto, el artículo 1, apartado 3 a), prevé que las partes litigantes no podrán apartarse del Reglamento, ni mediante acuerdo ni de ningún otro modo, a menos que el tratado se lo permita.

87. El **Sr. Lebedev** (Federación de Rusia) pide que, para evitar ambigüedades, ese entendimiento se recoja en el informe de la Comisión.

88. *Así queda acordado.*

89. *Queda aprobado el artículo 6.*

Se levanta la sesión a las 16.55 horas.

Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (continuación)

Acta resumida de la 960ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena, Viena, el martes 9 de julio de 2013, a las 9.30 horas

[A/CN.9/SR.960]

Presidente interino: Sr. Moollan (Presidente del Grupo de Trabajo II) (Mauricio)

Se declara abierta la sesión a las 9.50 horas.

Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación

a) Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (continuación) (A/CN.9/760, 765, 783 y 787 y Add.1, Add.1/Corr.1, Add.2 y Add.3)

Proyecto de artículo 1 – Ámbito de aplicación (continuación)

1. **El Presidente** observa que se ha propuesto añadir la expresión “en consulta con las partes litigantes” en el proyecto de artículo 1, apartado 3 b). La secretaría confirmó que, en principio, esa expresión se había incluido en el proyecto de reglamento sobre la transparencia siempre que se consideró apropiada. Por consiguiente, el orador sugiere que se añada después de “las circunstancias del caso”.
2. *Así queda acordado.*
3. **El Presidente** comunica que el grupo de redacción sugirió que se modificara ligeramente el nuevo texto de la última frase del párrafo 3 b) de la siguiente manera: “y si es coherente con el objetivo de transparencia de este Reglamento”.
4. *Así queda acordado.*
5. **El Presidente**, en relación con el proyecto de artículo 1, párrafo 9, y en respuesta a una observación de la secretaría, sugiere que se sustituya “arbitrajes entablados con arreglo a otros reglamentos de arbitraje” por “arbitrajes entablados de conformidad con otros reglamentos que no sean el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI”.
6. *Así queda acordado.*
7. **El Presidente** opina que antes del párrafo 9 habría que insertar un subtítulo.

8. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) propone el siguiente: “*Aplicación en arbitrajes que no estén sujetos al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI*”.

9. *Así queda acordado.*

10. **El Presidente** anuncia que la delegación de Suiza también desea proponer una modificación de la primera nota de pie de página relativa al párrafo 1.

11. **El Sr. Schöhl** (Suiza) propone que se suprima la frase “que contenga disposiciones sobre la protección de las inversiones o los inversionistas” tanto en el párrafo 1 como en la primera nota correspondiente a ese párrafo porque la nota de pie de página 1, que figura más adelante, ya se refiere a esa protección.

12. **El Sr. Apter** (Israel) hace hincapié en la importancia de establecer claramente en el propio Reglamento, y no en una nota, que por “tratado” se entiende todo tratado que establezca la protección de las inversiones o los inversionistas.

13. **El Presidente** hace suya esa opinión. La secretaría sugirió que la frase en cuestión únicamente se suprimiera de la nota de pie de página y que el asterisco se colocase después de “(‘el tratado’)” en el párrafo 1.

14. *Así queda acordado.*

15. *Queda aprobado el artículo 1 en su forma enmendada.*

Artículo 4 – Escritos presentados por terceros; proyecto de artículo 5 – Escritos presentados por partes en el tratado no litigantes (continuación)

16. **El Presidente** se refiere a las deliberaciones sostenidas en la sesión anterior acerca de la armonización del texto del artículo 4, párrafo 3, que contiene la frase “Para determinar si permite la presentación de un escrito”, con el proyecto de artículo 5, párrafo 2, en que figura la frase “En el ejercicio de sus facultades discrecionales en cuanto a aceptar o no tales escritos”, y observa que esa diferencia de formulación es deliberada, ya que en el

primer caso no se hace referencia al ejercicio de facultades discrecionales en general por parte del tribunal arbitral. En consecuencia, el orador sugiere que no se modifique el texto del artículo 4, párrafo 3.

17. *Así queda acordado.*

18. **El Presidente** también sugiere que no se modifique el texto del proyecto de artículo 5, párrafo 2, pero que en el informe de la Comisión se haga notar que durante las deliberaciones del Grupo de Trabajo II y de la Comisión se expresó preocupación reiteradamente ante la posibilidad de que la disposición abriera una vía a la protección diplomática y se destacó la necesidad de establecer expresamente que no es esa la intención. La Comisión también podría invitar a los tribunales arbitrales que ejercerán facultades discrecionales con arreglo al proyecto de artículo 5, párrafo 2, a que tengan eso en cuenta. El examen de ese asunto queda aplazado hasta la sesión siguiente.

Proyecto de artículo 7 – Excepciones a la norma de la transparencia

19. **El Presidente** recuerda que el proyecto de artículo 7 está comprendido en la propuesta de transacción revisada que el Grupo de Trabajo II apoyó de manera formal y unánime.

20. El orador invita a formular observaciones sobre las cuestiones de redacción enunciadas en el párrafo 25 del documento A/CN.9/783.

21. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) comprende que las palabras “o de las partes en el tratado no litigantes” se añadieron al párrafo 5 a efectos de compatibilizarlo con los párrafos anteriores. Preferiría que esas palabras se suprimieran tanto del párrafo 1 como del párrafo 3 porque en los artículos anteriores no se hizo una distinción entre el público y las partes en el tratado no litigantes.

22. **El Presidente** observa que esa distinción se ha hecho porque los artículos 4 y 5 tratan por separado de las partes en el tratado no litigantes y los terceros. Sin embargo, conviene en que en los artículos 2 y 3 el término “público” abarca a las partes no litigantes. Eso podría aclararse en el informe de la Comisión.

23. El **Sr. Apter** (Israel) apoya la propuesta del delegado del Canadá y destaca la necesidad de establecer claramente, tal vez en una nota de pie de página, que el término “público” abarca a las partes no litigantes.

24. **El Presidente** sugiere que se inserte una nota de pie de página la primera vez que se use “el público” a fin de

aclarar que engloba a “los terceros” y a “las partes en el tratado no litigantes”.

25. El **Sr. Brown** (Unión Europea) observa que en algunos países existe un requisito práctico con respecto a los tratados que se aplica a la información que se proporciona a las partes en el tratado no litigantes. En esas situaciones, la nota propuesta podría dar lugar a confusión.

26. **El Presidente** advierte que el hecho de no incluir una nota explicativa en el Reglamento también podría dar lugar a confusión.

27. La **Sra. Pólit** (Ecuador) sugiere que se haga una distinción desde el punto de vista jurídico entre el término “público”, que designa a cualquier persona, y un “tercero” o *amicus curiae*, que alude a una persona que tiene un interés especial en un caso presentado ante el tribunal arbitral.

28. **El Presidente** señala que en el artículo 4, párrafo 1, se emplea el término “tercero” para referirse a toda una categoría de personas que pueden tener un interés especial. Un número limitado de personas comprendidas en esa categoría pueden tener un interés considerable y, por lo tanto, reunir las condiciones para ser un *amicus curiae*. Además, el proyecto de artículo 5 trata de las partes en el tratado no litigantes.

29. El **Sr. Kordač** (Observador de la República Checa) recuerda que la cuestión planteada por el delegado de la Unión Europea se abordó en el artículo 1, párrafo 7, que regula los conflictos entre el Reglamento sobre la Transparencia y los reglamentos de arbitraje aplicables.

30. La delegación de su país considera que el alcance del término “público” debería aclararse en una nota de pie de página del Reglamento y no en el informe de la Comisión.

31. El **Sr. Lavranos** (Observador de los Países Bajos), el **Sr. Möller** (Observador de Finlandia) y el **Sr. Popkov** (Belarús) convienen en que las referencias al público y a las partes no litigantes que figuran en el texto en examen del proyecto de artículo 7 son suficientemente claras y no deberían modificarse.

32. **El Presidente** recuerda que, según la secretaría, la práctica de la Comisión es aclarar esas cuestiones en el informe, y no insertando una nota de pie de página en el texto en examen.

33. El **Sr. Apter** (Israel) dice que hay consenso sobre la cuestión sustantiva de que “el público” engloba a las partes no litigantes y a los terceros. No obstante, la falta de concordancia de la terminología empleada en los diferentes artículos puede dar lugar a problemas de interpretación.

Puesto que ya hay dos notas al pie del artículo 1, nada impide que se inserte otra a fin de aclarar un aspecto tan importante.

34. El **Sr. Räftegård** (Observador de Suecia) advierte que el hecho de indicar en una nota que “el público” abarca a los Estados partes no litigantes podría dar la impresión a los lectores de que las partes que no son Estados no están comprendidas en el término.

35. El **Presidente** dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión decide aclarar todos los aspectos de la cuestión en su informe.

36. *Así queda acordado.*

37. El **Sr. Kordač** (Observador de la República Checa) observa que algunas entidades a las que, en cumplimiento del artículo 4, se haya autorizado a presentar escritos en calidad de terceros podrían sostener que son participantes en el procedimiento y que deberían tener acceso a todos los documentos. No está seguro de que queden bien claros los derechos reconocidos a esas entidades en virtud del Reglamento.

38. El **Presidente** opina que no existe ambigüedad alguna en el Reglamento con respecto a sus derechos.

39. El **Sr. Cachapuz de Medeiros** (Brasil) expresa reservas acerca de las disposiciones del artículo 7 relativas a las excepciones a la norma de la transparencia en relación con la denominada “información confidencial”. En el Brasil se promulgó una ley por la que se abolió la categoría de información confidencial.

40. El **Presidente** señala que en el artículo se prevén excepciones con respecto a la información confidencial y a la información protegida.

41. El **Sr. Lee Jae Min** (República de Corea) observa que en el párrafo 3 se empleó la expresión “en consulta con las partes litigantes” y también se acaba de insertar esa expresión en el artículo 1, apartado 3 b). En todos los demás casos, incluida la última oración del proyecto de artículo 7, párrafo 3, se emplea “previa consulta con las partes litigantes”. Sin embargo, en el párrafo 7 se usa otra versión, a saber, “previa consulta con las partes litigantes cuando sea viable”.

42. El **Presidente** opina que habría que sustituir “en consulta” por “previa consulta” en todos los casos. La frase “cuando sea viable” se añadió a propósito para abarcar la circunstancia excepcional en que el tribunal arbitral, por iniciativa propia, tome medidas para limitar o aplazar la publicación de la información.

43. El **Sr. Agrawal** (India) propone que en el proyecto de artículo 7, párrafo 5, se sustituya la frase “cuya divulgación considere contraria a sus intereses de seguridad esenciales” por “cuya divulgación considere contraria al interés público o a sus intereses de seguridad esenciales”. La expresión “interés público” se usa ampliamente y se comprende bien en la India y en muchos otros países, en tanto que la expresión “intereses de seguridad esenciales” tiene un alcance más restringido.

44. El **Presidente** recuerda que el párrafo 5 ya fue objeto de un examen a fondo. La modificación propuesta es sustantiva y la Comisión no parece estar dispuesta a reabrir el debate.

45. El **Sr. Klippstein** (Alemania) propone trasladar al principio del párrafo 3 la oración que figura al final de este, relativa a la posibilidad de que el tribunal arbitral decida si determinada información es confidencial o protegida. El tribunal debería hacerlo antes de decidir la manera de evitar que la información pertinente se ponga al alcance del público o de partes no litigantes.

46. La **Sra. Perales Viscasillas** (España) y el **Sr. Brown** (Unión Europea) hacen suya la propuesta.

47. El **Sr. Jacquet** (Francia) indica que en el encabezamiento del párrafo 3 se presume que no existe desacuerdo alguno en torno al hecho de que cierta información sea confidencial o protegida. La última oración, por el contrario, tiene por objeto solucionar un problema concreto, a saber, una situación en la que las partes litigantes no se pongan de acuerdo en si se trata de información confidencial o protegida. Por consiguiente, su delegación preferiría que el párrafo no se modificara.

48. El **Presidente** observa que esa explicación ha convencido a los miembros de la Comisión, entre ellos el delegado de Alemania.

49. De no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el proyecto de artículo 7 con las modificaciones introducidas.

50. *Queda aprobado el artículo 7.*

Se suspende la sesión a las 10.50 horas y se reanuda a las 11.10 horas.

Proyecto de modificación del artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI

51. El **Presidente** dice que el ámbito de aplicación del Reglamento sobre la Transparencia, enunciado en su artículo 1, exige modificar el artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI con objeto de crear un vínculo

entre los dos instrumentos. En el párrafo 29 del documento A/CN.9/783 figura el texto de un nuevo párrafo 4 que se propone añadir al artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

52. En primer lugar, cabe estudiar si el Reglamento sobre la Transparencia debería figurar como apéndice del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Habida cuenta de que la Comisión convino en que hay un vínculo entre los dos conjuntos de normas, aunque solo para futuros tratados, parece razonable que, en atención a los usuarios, cuando se publique la versión de 2014 del Reglamento de Arbitraje, este vaya acompañado del Reglamento sobre la Transparencia en forma de apéndice o de algún otro modo. En principio, la forma que se adopte no debería disuadir a los interesados de emplearlo en otros contextos, por ejemplo, en conjunción con los reglamentos de otras instituciones, en procedimientos en curso regulados por el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI o en procedimientos futuros que se tramiten con arreglo a tratados vigentes. A juicio del orador, el Reglamento sobre la Transparencia debería figurar en el mismo documento que contenga el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2014, pero no debería llamarse apéndice. También debería publicarse por separado.

53. El **Sr. Cachapuz de Medeiros** (Brasil) opina que el Reglamento sobre la Transparencia debería ser un instrumento independiente y no debería formar parte del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

54. El **Sr. Popkov** (Belarús) no tiene objeciones acerca de la modificación del artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, ni de la incorporación del Reglamento sobre la Transparencia en el mismo documento del Reglamento de Arbitraje de 2014. No obstante, concuerda con el representante del Brasil en que debería ser un instrumento independiente.

55. La **Sra. Liang Danni** (China), la **Sra. Szymanska** (Observadora de Polonia) y el **Sr. Apter** (Israel) también se suman a la propuesta del representante del Brasil.

56. La **Sra. Kobayashi-Terada** (Japón) desea saber si los dos conjuntos de normas estarán juntos y también por separado en el sitio web del archivo.

57. El **Presidente** propone que en el artículo 1, párrafo 4, del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI figure un hiperenlace que remita al lector al Reglamento sobre la Transparencia.

58. El **Sr. Lebedev** (Federación de Rusia) opina que la formulación actual no aclara el estatus del Reglamento sobre la Transparencia, que sin duda es el de un

instrumento independiente. Todavía hay cierto grado de ambigüedad, especialmente porque el Reglamento sobre la Transparencia se publicará conjuntamente con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El orador desea saber si seguirá existiendo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010, o si será sustituido por la versión de 2013.

59. El **Presidente** recuerda que el estatus del Reglamento sobre la Transparencia está enunciado claramente en su artículo 1, en particular en la frase “a menos que las partes en el tratado hayan acordado otra cosa”. En consecuencia, es preciso modificar el artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Al respecto, el orador señala la solución de transacción a que se hace referencia en los párrafos 79 y 80 del informe del Grupo de Trabajo II (A/CN.9/765).

60. En lo que atañe al estatus del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010, el orador señala a la atención de la Comisión el párrafo 31 del informe sobre la solución de controversias comerciales (A/CN.9/783): “Una referencia al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI aprobado en 1976, o al revisado en 2010, en un tratado concertado después de la entrada en vigor del reglamento sobre la transparencia tendría el efecto de impedir la aplicación del reglamento sobre la transparencia”.

61. El **Sr. Lebedev** (Federación de Rusia) indica que los documentos citados por el Presidente son un informe del Grupo de Trabajo y una nota de la Secretaría. Con referencia al párrafo 34 del documento A/CN.9/783, opina que la Comisión debe decidir formalmente si el Reglamento sobre la Transparencia será un instrumento independiente. Su delegación todavía no está convencida de que su estatus quede claro, pero si otras delegaciones no tienen dudas al respecto, se sumará al consenso.

62. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) apoya los argumentos expuestos por el Presidente. Dado que el Reglamento sobre la Transparencia indudablemente es un instrumento independiente, es preferible, para actuar de buena fe y evitar dar una falsa impresión, que no figure como apéndice.

63. La **Sra. Perales Viscasillas** (España) destaca la importancia de que el formato visual de la publicación que contenga el Reglamento sobre la Transparencia no cree confusión a los usuarios y el público en general. Si bien se trata de un instrumento independiente, es evidente que el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI ha de remitirse a él. Debería destacarse el hecho de que este último se aplica mayormente en controversias comerciales, en tanto que el

Reglamento sobre la Transparencia se aplicará en controversias relacionadas con inversiones.

64. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) opina que también cabe hacer hincapié en la autonomía del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y evitar lo que podría denominarse “contaminación” con el Reglamento sobre la Transparencia.

65. El **Sr. Jacquet** (Francia) observa que el Reglamento sobre la Transparencia tiene un doble propósito. El artículo 1, que regula su alcance en relación con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, establece que se aplicará a los arbitrajes de la CNUDMI. Con carácter de reglamento independiente, también lo podrán utilizar las partes en una controversia que sea ajena al contexto del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Cabe destacar esa distinción y abstenerse de emplear una terminología incompatible con ese objetivo.

66. El **Presidente** entiende que la Comisión desea dar instrucciones a la secretaría para que publique el Reglamento sobre la Transparencia tanto conjuntamente con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI como en calidad de documento independiente que estará al alcance del público en general.

67. *Así queda acordado.*

68. El **Sr. Agrawal** (India) expresa reservas acerca del uso de la palabra “incluye” en la frase “el presente Reglamento incluye el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia” del texto propuesto del nuevo artículo 1, párrafo 4, del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, aun cuando en el artículo 1 del Reglamento sobre la Transparencia queda claro que puede optarse por no aplicarlo. Propone la siguiente variante: “el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia complementará el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI”.

69. El **Sr. Apter** (Israel) propone que en el proyecto de párrafo 4 se suprima la expresión “con las modificaciones que puedan introducirse ocasionalmente”, que figura entre corchetes después de “Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia”. También propone que, cuando se publique el Reglamento sobre la Transparencia, se añada la fecha al título, por ejemplo, Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia 2013, ya que con el tiempo podría aprobarse una versión modificada.

70. El **Presidente** se remite al nuevo título aprobado cuando se volvió a publicar la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno 1996, y sugiere que se añada “con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado

en 2014” al título del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

71. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) propone que el título del Reglamento sobre la Transparencia sea “Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado”.

72. El **Presidente** dice que dará tiempo a la Comisión para reflexionar sobre los títulos.

73. Invita a formular observaciones acerca de la propuesta de suprimir la expresión “con las modificaciones que puedan introducirse ocasionalmente”, que figura entre corchetes después de “Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia”.

74. El **Sr. Lavranos** (Observador de los Países Bajos) propone que la expresión se sustituya por “en vigor en la fecha de apertura del procedimiento de arbitraje”.

75. El **Sr. Lawalata** (Indonesia) desea saber qué consecuencias tendría para los tratados la formulación propuesta por el delegado de los Países Bajos.

76. El **Presidente** dice que, si las partes en un tratado que se haya concertado, por ejemplo, en 2016, decidieran aplicar el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2014, con la expresión “en vigor en la fecha de apertura del procedimiento de arbitraje”, y el Reglamento sobre la Transparencia se modificase en 2020, una controversia planteada en 2025 se regiría por la versión modificada del Reglamento. Actualmente se aplican principios análogos a la mayoría de los acuerdos de arbitraje.

77. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) recuerda que el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 está basado en la presunción de que será aplicable en el momento de iniciarse el proceso arbitral. Cree entender que la formulación propuesta por el delegado de los Países Bajos no entraña esa presunción.

78. El **Sr. Lavranos** (Observador de los Países Bajos) considera conveniente añadir una disposición de transición que se aplique a todos los arbitrajes que no estén comprendidos en el régimen establecido por el artículo 1, párrafo 4, de la nueva versión del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Esa disposición podría basarse en el artículo 1, párrafo 2, del Reglamento de Arbitraje de 2010.

79. El **Presidente** sugiere que esa disposición se incorpore en el artículo 1 del Reglamento sobre la Transparencia.

80. La **Sra. Rennie** (Reino Unido) solicita que la decisión correspondiente se aplaze hasta la siguiente sesión.

81. **El Presidente** señala a la atención de la Comisión el párrafo 36 del documento A/CN.9/783, en que se solicita a esta que considere la posibilidad de insertar en el artículo 1, párrafo 4, de su Reglamento de Arbitraje la

misma nota que figura al pie del artículo 1 del Reglamento sobre la Transparencia.

82. De no haber ninguna expresión de apoyo, se entenderá que la Comisión desea rechazar la sugerencia.

83. *Así queda acordado.*

Se levanta la sesión a las 12.25 horas.

Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (continuación)

Acta resumida de la 961ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena, Viena, el martes 9 de julio de 2013, a las 14.00 horas

[A/CN.9/SR.961]

Presidente interino: Sr. Moollan (Presidente del Grupo de Trabajo II) (Mauricio)

Más tarde: Vicepresidente: Sr. Moollan (Vicepresidente) (Mauricio)

Se declara abierta la sesión a las 14.20 horas.

Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación

a) Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (continuación) (A/CN.9/760, 765, 783 y 787 y Add.1, Add.1/Corr.1, Add.2 y Add.3)

Proyecto de artículo 5 – Escritos presentados por partes en el tratado no litigantes (continuación)

1. **El Presidente** recuerda que algunos miembros de la Comisión apoyaron la aprobación del proyecto de artículo 5, párrafo 2, sin modificaciones, siempre y cuando se aclarara en el informe que la intención no era permitir el ejercicio de la protección diplomática. Otros deseaban que ese aspecto se tratara en el propio párrafo, o que este se suprimiera por completo.

2. Como solución de avenencia, se propuso que se pusiera una coma al final de la segunda oración y se añadiera el siguiente texto: “, y la necesidad de evitar que una parte no litigante presente escritos en los que apoye la reclamación de un inversionista de modo tal que equivalga a protección diplomática”.

3. El **Sr. Brown** (Unión Europea) dice que el texto en estudio del párrafo 2 se remite al artículo 4, párrafo 3, en el que se enumeran los factores que el tribunal arbitral ha de tener en cuenta para decidir si permite la presentación de un escrito. Desea saber si la protección diplomática mencionada en la nueva versión es otro factor que ha de tenerse en cuenta.

4. **El Presidente** dice que es otro factor, pero totalmente separado.

5. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) y el **Sr. Galindo** (Ecuador) piden tiempo para examinar la propuesta.

6. **El Presidente** dice que podría adoptarse una decisión tras la pausa que se hará para celebrar consultas.

Proyecto de modificación del artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (continuación)

7. **El Presidente** recuerda a la Comisión las dos variantes propuestas para modificar el nuevo proyecto de artículo 1, párrafo 4, del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. La primera de ellas es que se retiren los corchetes de la expresión “con las modificaciones que puedan introducirse ocasionalmente”. La segunda consiste en sustituir esa expresión por “en vigor en la fecha de apertura del procedimiento de arbitraje”.

8. Algunas delegaciones preguntaron si las dos modificaciones propuestas entrañaban diferencias sustantivas. No parece ser así. La segunda modificación propuesta solo recoge el texto utilizado en el artículo 1, párrafo 2, del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 y deja claro que, si se modifica el Reglamento sobre la Transparencia, regirá la versión modificada.

9. Otras delegaciones señalaron cuestiones de política. Podría ser difícil que los Estados aceptaran el Reglamento sobre la Transparencia en su formulación inicial y más aún que aceptaran la posibilidad de tener que aplicar versiones modificadas.

10. La **Sra. Kobayashi-Terada** (Japón) observa que en el artículo 1, párrafo 2, figura la frase “a menos que las partes hayan acordado que su litigio se rija por una versión determinada del Reglamento” después de “en vigor en la fecha de apertura del procedimiento de arbitraje”, y desea saber si se empleará la misma formulación en el artículo 1, párrafo 4.

11. **El Presidente** dice que eso se podría hacer si la Comisión así lo decidiera.

12. El **Sr. Apter** (Israel) advierte que la expresión “con las modificaciones que puedan introducirse ocasionalmente” disuadirá a los Estados de aplicar el

Reglamento sobre la Transparencia y de adoptarlo en tratados futuros.

13. La **Sra. Rennie** (Reino Unido) indica que su delegación comparte la preocupación de que la vaguedad de la expresión “con las modificaciones que puedan introducirse ocasionalmente” pudiese disuadir a los Estados de aplicar el Reglamento sobre la Transparencia.

14. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) hace suyos los argumentos planteados por los dos oradores anteriores.

15. El **Sr. Jaquet** (Francia) dice que, cuando se modifique el Reglamento sobre la Transparencia, es casi seguro que la nueva versión contenga una disposición que establezca las condiciones de aplicación, que podrían ser incompatibles con la frase “con las modificaciones que puedan introducirse ocasionalmente”. Por lo tanto, incluir esa frase no tiene sentido y hasta puede llegar a ser contraproducente. Propone como solución que se añada la palabra “aplicable” después de “el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia”.

16. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) sugiere la siguiente variante: “el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en vigor en 2014, a menos que las partes hayan acordado que su litigio se rija por una versión posterior del Reglamento”.

17. El **Presidente** advierte del riesgo de complicar innecesariamente la cuestión en examen. Nada impide que en el tratado se declare que se aplicará la versión más reciente del Reglamento sobre la Transparencia. Sugiere que la Comisión omita todo texto evolutivo, como en el caso de la versión de 1976 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

18. De no haber objeciones, cabe entender que la Comisión está de acuerdo con esa sugerencia.

19. *Así queda acordado.*

20. El **Presidente** recuerda a la Comisión el título propuesto en la sesión anterior: “Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado”.

21. También se propuso el siguiente título: “Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2014)”.

22. La **Sra. Perales Viscasillas** (España) propone que en la versión inglesa del segundo título se sustituya “*revised*” por “*new*”, dado que el párrafo 4 se añade al artículo 1.

23. *Así queda acordado.*

24. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) propone que se sustituya “2014” por “2013”, ya que el nuevo artículo 1, párrafo 4, presumiblemente entrará en vigor antes de fines de ese año.

25. *Así queda acordado.*

26. *Queda aprobado el artículo 1 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI en su forma enmendada.*

Se suspende la sesión a las 14.50 horas y se reanuda a las 16.05 horas.

Proyecto de artículo 5 – Escritos presentados por partes en el tratado no litigantes (continuación)

27. El **Presidente**, en relación con las consultas celebradas durante el receso, dice que en el texto en estudio del proyecto de artículo 5, párrafo 2, ya se mencionan los factores que debe tener en cuenta el tribunal arbitral, previstos en el artículo 4, párrafo 3. Entre ellos figura el hecho de que un escrito puede aportar enfoques, conocimientos particulares o puntos de vista distintos a los de las partes litigantes. En opinión de algunas delegaciones, esa disposición impediría, por sí misma, que una parte no litigante presentara un escrito que entrañara el ejercicio de la protección diplomática mencionado en el proyecto de artículo 5. Otras delegaciones discreparon y expresaron el deseo de que en el proyecto de artículo se hiciese referencia expresamente a la protección diplomática. Se señaló, sin embargo, que hacerlo daría a entender que la cuestión no está comprendida en el ámbito del artículo 4, párrafo 3.

28. Se propone que al final del proyecto de artículo 5, párrafo 2, se añada la nueva oración siguiente: “A fin de evitar dudas, en el ejercicio de sus facultades discrecionales en cuanto a permitir o no que se presenten tales escritos, el tribunal arbitral tendrá en cuenta la necesidad de evitar la presentación por una parte no litigante de escritos en que se apoye la reclamación de un inversionista de modo tal que equivalga a protección diplomática”. En el informe se dejará constancia de que, a juicio de varias delegaciones, esa frase es innecesaria, puesto que su contenido ya figura en el artículo 4, apartado 3 b).

29. El **Sr. Popkov** (Belarús) considera difícil que los tribunales arbitrales interpreten lo que se entiende por “equivalga a protección diplomática”. Cabe explicar que la preocupación principal es evitar una situación en la que una parte no litigante que intente promover los intereses de un inversionista por medios indebidos abuse del derecho de presentar escritos, aclarando que la protección diplomática no se aplica al tema objeto del Reglamento

sobre la Transparencia, habida cuenta, entre otras cosas, de la definición dada por la Comisión de Derecho Internacional acerca de la nacionalidad de las personas jurídicas en el contexto de la protección diplomática.

30. **El Presidente** recuerda que ya se ha considerado la posibilidad de añadir un texto como, por ejemplo, “que equivalga a la adhesión de la parte no litigante a la reclamación del inversionista”. La idea que la Comisión trata de reflejar es el ejercicio encubierto de la protección diplomática, en otras palabras, una situación en la que un Estado actúe en apoyo de un inversionista.

31. El **Sr. Lee Jae Min** (República de Corea) desea saber si una parte no litigante no estaría facultada para expresar ninguna opinión en apoyo de los objetivos de un inversionista, aun cuando eso no equivaliera al ejercicio de la protección diplomática.

32. **El Presidente** señala que la mayoría de los escritos presentados por los Estados tendrían el efecto de prestar apoyo a una u otra de las partes. Por lo tanto, no sería razonable establecer que todos esos escritos son inadmisibles. Corresponde al tribunal arbitral determinar la clase de apoyo que se está ofreciendo.

33. El **Sr. Lee Jae Min** (República de Corea), con referencia al proyecto de artículo 5, párrafo 1, advierte que los escritos presentados por las partes no litigantes en relación con la interpretación del tratado también podrían redundar en apoyo indebido a una parte.

34. **El Presidente** señala que el Estado de origen de la parte litigante con frecuencia dará su propia interpretación del tratado. Por consiguiente, tal vez sería conveniente escuchar otra opinión que sirviera de contrapeso, si bien esos escritos pertenecen a una categoría diferente.

35. Se aplaza el examen del proyecto de artículo 5, párrafo 2, hasta la sesión siguiente.

Elección de autoridades (continuación)

36. La **Sra. Kagwanja** (Kenya), haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de los Estados de África, propone la candidatura del Sr. Moollan (Mauricio) al cargo de Vicepresidente de la Comisión.

37. *Por aclamación, el Sr. Moollan queda elegido Vicepresidente de la Comisión.*

Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación

- a) **Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (continuación)** (A/CN.9/760, 765, 783 y 787 y Add.1, Add.1/Corr.1, Add.2 y Add.3)

Artículo 3 – Publicación de documentos (continuación)

38. **El Presidente** anuncia que se acaba de publicar un documento del grupo de redacción (A/CN.9/XLVI/CRP.2) que contiene la versión modificada del artículo 3, párrafo 5, y suspende la sesión a fin de dar tiempo a los miembros para decidir si esa versión es aceptable.

Se suspende la sesión a las 16.25 horas y se reanuda a las 16.35 horas.

39. **El Presidente** pregunta si el texto en estudio del artículo 3, párrafo 5, es aceptable: “Las personas que, sin ser partes litigantes, reciban acceso a documentos con arreglo a lo establecido en el párrafo 3 sufragarán los gastos administrativos que conlleve facilitar el acceso de esas personas a los documentos, como los gastos de fotocopiado o envío de los documentos a esas personas, pero no los gastos administrativos que conlleve facilitar el acceso del público a esos documentos por medio del archivo”.

40. La **Sra. Rennie** (Reino Unido) propone la siguiente variante: “Las personas que reciban acceso a documentos con arreglo a lo establecido en el párrafo 3 sufragarán los gastos administrativos que conlleve facilitar el acceso de esas personas a los documentos, como los gastos de fotocopiado o envío de los documentos a esas personas, pero no los gastos que conlleve facilitar el acceso del público a esos documentos por medio del archivo”.

41. **El Presidente** señala que la frase “que no sea parte litigante” es innecesaria, ya que, evidentemente, quienes reciban acceso a documentos con arreglo al párrafo 3 no son partes litigantes.

42. El **Sr. Brown** (Unión Europea) propone que se supriman las palabras “a esas personas” después de “envío de los documentos”.

43. El **Sr. Castello** (Estados Unidos de América) observa que, si se suprimiera “a esas personas”, podría darse a entender que los gastos de fotocopiado o envío al archivo deberían ser sufragados por las personas que recibieran acceso a los documentos.

44. **El Presidente** entiende que la Comisión aprueba la versión editada del artículo 3, párrafo 5, propuesta por la representante del Reino Unido.

45. *Así queda acordado.*

Se levanta la sesión a las 16.45 horas.

Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (continuación)

Acta resumida de la 962ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena, Viena, el miércoles 10 de julio de 2013, a las 9.30 horas

[A/CN.9/SR.962]

Presidente: Sr. Moollan (Vicepresidente) (Mauricio)

Se declara abierta la sesión a las 9.50 horas.

Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación

- a) Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (continuación)** (A/CN.9/760, 765, 783, 787 y Add.1, Add.1/Corr.1, Add.2 y Add.3, y 793)

Proyecto de artículo 8 – Archivo de la información publicada

1. **El Presidente** propone que la Comisión proceda bajo la presunción de que el reglamento habrá de entrar en vigor el 1 de abril de 2014. Ello dará a la CNUDMI el tiempo necesario para procurar financiación extrapresupuestaria. Propone además que se encomiende a la secretaría contactarse con la Quinta Comisión y la Sexta Comisión de la Asamblea General, si fuera necesario. Como no cabe esperar una decisión de la Asamblea General antes de fines de diciembre de 2013, la fecha de entrada en vigor que acaba de sugerir también sería adecuada en esas circunstancias.

2. Se ha propuesto la redacción siguiente para el proyecto de artículo 8 del reglamento sobre la transparencia: “El archivo de la información publicada conforme al Reglamento sobre la Transparencia será el Secretario General de las Naciones Unidas, por conducto de la secretaría de la CNUDMI o una institución nombrada por la CNUDMI”.

3. La Comisión tuvo el privilegio de haber recibido ofrecimientos de asistencia de dos instituciones de la máxima reputación y con un gran volumen de trabajo: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). Ambas instituciones se han ofrecido a asumir las funciones de archivo y también han confirmado que, no bien la CNUDMI les informe que se encuentra en condiciones de actuar como archivo, transferirán esas

funciones sin costo para la Comisión. El orador espera que la Comisión pueda llegar al consenso respecto de la designación de una de las instituciones.

4. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) pregunta si sería posible establecer una fecha de entrada en vigor del reglamento anterior al 1 de abril de 2014, puesto que la Comisión ya está preparando la designación de una institución que actúe como archivo de resguardo.

5. La **Sra. Rennie** (Reino Unido) pregunta si la Comisión prevé solicitar a las Comisiones Quinta y Sexta de la Asamblea General financiación adicional para la secretaría de la CNUDMI con cargo al presupuesto ordinario.

6. **El Presidente** dice que tiene entendido que algunos miembros de la Comisión consideran que la financiación deberá aportarse sin que ello entrañe un costo adicional.

7. De no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar la propuesta de encomendar a la secretaría que se ponga en contacto con las Comisiones Quinta y Sexta de la Asamblea General.

8. *Así queda acordado.*

9. La **Sra. Escobar** (El Salvador) propone añadir la palabra “temporalmente” después de “nombrada”.

10. **El Presidente** dice que la Comisión no puede adoptar por adelantado una decisión al respecto, porque existe una leve posibilidad de que la CNUDMI no pueda conseguir recursos del presupuesto ordinario ni extrapresupuestarios.

11. Considera que la Comisión desea aprobar la versión enmendada del proyecto de artículo 8 del reglamento sobre la transparencia.

12. *Queda aprobado el artículo 8, en su versión enmendada.*

13. **El Presidente** dice que sugirió el 1 de abril de 2014 como fecha de entrada en vigor del reglamento porque de esa manera se maximizan las posibilidades de obtener

financiación con cargo al presupuesto ordinario, o bien los fondos necesarios de origen extrapresupuestario. Para esa fecha también ya se debería contar con un archivo.

14. De no haber objeciones, considerará que la Comisión conviene en el 1 de abril de 2014 como fecha de entrada en vigor del reglamento sobre la transparencia.

15. *Así queda acordado.*

16. **El Presidente** invita a hacer uso de la palabra al representante de la Corte Permanente de Arbitraje.

17. El **Sr. Daly** (Corte Permanente de Arbitraje) dice que la Corte comprende que las limitaciones presupuestarias impiden por el momento que la CNUDMI asuma la función de archivo. Respecto de la decisión sobre qué institución podría designarse entre tanto, ambas opciones resultan atractivas habida cuenta de la gran experiencia de los dos organismos. En 1968 la CPA concluyó un acuerdo de cooperación con el CIADI y desde entonces ha cooperado estrechamente con el Centro.

18. La CPA es una organización intergubernamental fundada en 1899 con arreglo a la Convención de La Haya para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales, que fue revisada en 1907. Los instrumentos fundacionales de 1899 y 1907 especifican que la Corte será accesible en todo momento y para todos los Estados, aun aquellos que no hayan firmado alguno de los instrumentos fundacionales, y que la Oficina Internacional de la CPA actúa como registro en el procedimiento y mantiene un archivo de sus causas.

19. La labor de la CPA está vinculada estrechamente al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Con arreglo a las versiones de 1976 y 2010 del Reglamento, su función es designar a la autoridad nominadora cuando las partes no hayan convenido en dicha autoridad. Hasta la fecha, ha entendido en unas 500 solicitudes de ese tipo. También se ha pedido frecuentemente a la CPA la prestación de servicios administrativos en procedimientos tramitados con arreglo al Reglamento de la CNUDMI u otros reglamentos, por ejemplo, para gestionar depósitos, mantener archivos u organizar audiencias en distintas partes del mundo. En la actualidad administra 78 arbitrajes, de los que 7 son arbitrajes entre Estados, 50 son arbitrajes entre inversionistas y Estados con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y 21 son demandas contractuales. En la mayoría de las 50 causas tramitadas con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, la CPA desempeña la función de archivo. Gestiona aproximadamente dos terceras partes de todas las controversias conocidas entre inversionistas y Estados. La CPA también tiene a su cargo el archivo más grande de

documentos sobre los arbitrajes entre inversionistas y Estados celebrados con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

20. Si bien en las causas tramitadas hasta la fecha la transparencia ha sido limitada, se puede percibir una ligera tendencia en pro de una mayor transparencia y no cabe duda de que la aprobación del reglamento sobre la transparencia reforzará esa tendencia. En consecuencia, la CPA está elaborando una base de datos y un motor de búsqueda nuevos que podrían adaptarse para satisfacer toda necesidad que la CNUDMI determinara para el archivo.

21. La creación y el mantenimiento del archivo será sin cargo alguno para los Estados Miembros de las Naciones Unidas o los Estados miembros de la CPA. La CPA no cobrará cargos de archivo en los casos que se requiera la publicación de menos de 50 documentos. Para los casos de más de 50 documentos, cobrará una tarifa plana de 750 euros, que es la misma que se cobra para designar una autoridad nominadora con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. La información publicada se podrá consultar y estará a disposición de terceros gratuitamente. Cuando se soliciten copias de los documentos publicados, la CPA requerirá a la parte solicitante el pago del costo de fotocopias y envío postal.

22. La CPA está en plenas condiciones de cooperar con la CNUDMI, si se lo solicitara, en otros asuntos relacionados con la función de archivo. Hay una larga historia de cooperación con las Naciones Unidas. Por ejemplo, en 2009 el Secretario General de las Naciones Unidas manifestó que esperaba con interés fortalecer la asociación entre la CPA y las Naciones Unidas en su empeño por progresar en el arreglo pacífico de controversias con arreglo al derecho internacional y construir para todos un mundo más seguro y mejor. Si bien el Secretario General se refería en particular a la labor de la CPA en la solución de conflictos armados, no cabe duda de que los miembros de la Comisión convendrán en que el arbitraje entre inversionistas y Estados se puede volver extremadamente enconado.

23. La **Sra. Kinneer** (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) dice que conviene con las observaciones del representante de la CPA respecto de la estrecha relación que existe entre las dos instituciones.

24. El CIADI es miembro del Grupo del Banco Mundial, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Tiene 149 Estados miembros que no pagan cuotas y prácticamente todos ellos son Estados Miembros de las

Naciones Unidas. En caso de actuar como archivo, el CIADI no cobraría a los Estados cargos directos ni indirectos.

25. El CIADI se creó con el propósito de realizar arbitrajes en materia de inversiones y ha tramitado más del 70% de todas las causas conocidas de ese tipo. El CIADI tramita las causas con arreglo a las normas que soliciten las partes. Si bien la mayoría de las 435 causas tramitadas hasta la fecha han sido causas de inversiones del CIADI, también ha tramitado 36 causas de la CNUDMI y cinco causas exclusivamente *ad hoc*. También ha sido designado autoridad nominadora en muchos tratados y se le puede solicitar que actúe como tal con arreglo al artículo 6 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Además, en virtud de numerosos tratados, actúa como autoridad encargada de la nominación de tribunales de consolidación.

26. La oradora acoge complacida la decisión de la Comisión, adoptada con arreglo a lo establecido en el artículo 1 del reglamento sobre la transparencia, de que el reglamento no solo se aplicará a las causas de la CNUDMI, sino que también servirá de modelo para la transparencia en el futuro. En consecuencia, como el reglamento se utilizará cada vez más en las causas tramitadas por el CIADI, parece lógico designar al CIADI como archivo en el interin. Hasta el momento, el CIADI es el único organismo que ha incorporado la transparencia en sus normas y práctica cotidiana. Los Estados podrán beneficiarse de esos antecedentes de tan larga data.

27. En el último año fiscal, el CIADI publicó los detalles de más de 1.400 laudos, medidas procesales y otros documentos relacionados con las causas. Publica en su sitio web ese tipo de información desde 1998, y desde 2007 ofrece una capacidad de búsqueda básica, avanzada y de texto completo para los textos en español, francés e inglés. Puede aprovechar los altos estándares tecnológicos del Banco Mundial, que permiten asegurar la información, y ya cuenta con los sistemas de dotación de personal necesarios. En caso de actuar como archivo, los usuarios podrán realizar búsquedas en toda la jurisprudencia del CIADI publicada por el archivo con arreglo al reglamento sobre la transparencia. De esa manera, el reglamento pasaría a ser verdaderamente efectivo y universal.

28. La propuesta del CIADI es muy eficaz en relación con los costos, ya que no se requiere financiación de los Estados y la secretaría de la CNUDMI tampoco deberá sufragar costo alguno. El cobro a las partes en una controversia de un cargo único mínimo, de

unos 1.500 dólares a 2.000 dólares, ayudará a evitar que se entablen demandas temerarias.

29. Respecto de la capacidad, el CIADI ofrecerá todas las características especificadas por el Grupo de Trabajo II. También actualiza constantemente su sitio web.

30. La gestión del archivo por el CIADI estará completamente separada de la tramitación de las causas. En consecuencia, los Estados y las partes en una controversia podrán hacer sus presentaciones ante los tribunales arbitrales y solicitar que se apliquen las excepciones a la transparencia establecidas en el artículo 7 antes de que se proceda a la publicación.

31. Por último, el CIADI podrá comenzar a actuar como archivo en unos dos o tres meses. Sin embargo, la oradora subraya que, a lo largo de los debates sobre el reglamento sobre la transparencia, el CIADI prestó apoyo a la opinión de que la CNUDMI misma sería el archivo ideal. Confirma que, no bien la CNUDMI cuente con financiación suficiente, el CIADI le transferirá todas las publicaciones pertinentes y le seguirá ofreciendo apoyo tecnológico, si fuera necesario.

32. El Sr. **Sorieul** (Secretario de la Comisión) destaca que la secretaría de la CNUDMI no compite por la función de archivo. Como no es una institución de arbitraje, en tal sentido es completamente neutral. Sin embargo tiene muy en cuenta que, cuando se apruebe el reglamento sobre la transparencia, será necesario hacerlo atractivo a los Estados que no son miembros de la CPA ni del CIADI y que no son necesariamente usuarios del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. En ese contexto, la Secretaría de las Naciones Unidas ha asegurado a la secretaría de la CNUDMI su apoyo a la promoción del servicio público que presta la transparencia.

33. Respecto del problema básico de la financiación, el sistema establecido por la CNUDMI podría tanto ser gratuito como cobrarse un cargo. Si se requiriera a las partes litigantes sufragar los gastos, los fondos así obtenidos no se usarían para sufragar el costo del archivo a cargo de la CNUDMI; se los reintegraría al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y se deducirían de las cuotas que los Estados Miembros pagan a la Organización.

34. El orador considera que, en los meses próximos, será posible establecer en la secretaría el equipo pequeño necesario para operar el archivo. Ya se han adoptado medidas para actualizar el sitio web y facilitar el acceso a la jurisprudencia de la CNUDMI.

35. Se ha preguntado si la CNUDMI está incluida en la lista de organizaciones de asistencia oficial para el

desarrollo compilada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El orador puede responder inequívocamente que sí lo está, pero incluida como Naciones Unidas, ya que la CNUDMI no tiene personalidad jurídica independiente. Confía en que la Comisión confirmará que el objetivo del reglamento sobre la transparencia y el archivo es promover el desarrollo y bienestar económicos, y que la transparencia es un valor fundamental de la buena gobernanza y el estado de derecho.

36. **El Presidente** dice que considera que la Comisión hace suya esa opinión.

37. *Así queda acordado.*

38. El **Sr. Cachapuz de Medeiros** (Brasil) dice que el CIADI fue creado por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. Como el Brasil no ha ratificado el Convenio, no reconoce la competencia del CIADI y, en consecuencia, se opone a que se lo designe como archivo.

39. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) dice que, en su opinión, la ratificación del Convenio del CIADI no debe ser un factor pertinente para decidir qué institución se debe designar para que desempeñe la función de archivo.

40. Solicita a la CPA información respecto de la capacidad de búsqueda en su sitio web, que es un requisito importante de la funcionalidad.

41. El **Sr. Daly** (Corte Permanente de Arbitraje) dice que la nueva base de datos de la CPA incluirá una búsqueda simple de palabras clave y varias opciones de búsqueda avanzada, que harán posible identificar las causas o los documentos según los factores siguientes: si el arbitraje está en trámite o ha concluido; tratado en virtud del cual se solicitó el arbitraje; tema; reglamento de arbitraje aplicable; institución administradora del arbitraje; árbitros; letrados de las partes; idioma de trámite de los procedimientos; sector económico; duración del trámite; año de comienzo del trámite o año de pronunciamiento del laudo o de finalización del trámite. Los resultados de la búsqueda se podrán filtrar de modo que muestren una lista de causas o documentos específicos que satisfagan determinados criterios. La base de datos podrá ser consultada públicamente por todos los usuarios sin necesidad de registrarse ni ingresar datos personales para conectarse. La opción más avanzada permitirá a los usuarios guardar el resultado de las búsquedas y que se les notifique por correo electrónico cada vez que se agreguen nuevos documentos sobre un tema en particular o pertinentes a una búsqueda anterior.

42. La **Sra. Perales Viscasillas** (España) dice que España es Estado parte tanto del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados como de la Convención de La Haya para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales. Considera que, en términos técnicos, tanto el CIADI como la CPA están perfectamente calificados para desempeñar las funciones de archivo. El único factor que aparentemente altera el equilibrio en favor de la CPA es su estrecha vinculación con los procedimientos tramitados con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. En 1976 la Comisión decidió, en el Reglamento de Arbitraje, asignar al Secretario General de la CPA la función institucional de designar la autoridad nominadora, y en 2010 aumentó la función administrativa en apoyo de las partes y los árbitros que actúen con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Las opciones previstas en los tratados de inversiones incluyen, por un lado, el arbitraje institucional del CIADI y, por el otro, el arbitraje *ad hoc* de la CNUDMI. En opinión de España, la asignación de la función de archivo al CIADI respecto de los procedimientos *ad hoc* podría dar lugar a confusión. Los dos tipos de arbitraje deben mantenerse separados a fin de evitar toda ambigüedad o malentendido. En consecuencia, España considera que la función de archivo debe asignarse a la CPA.

43. La **Sra. Polit** (Ecuador) dice que varios países de América Latina y el Caribe, por ejemplo, los Estados Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se oponen a la manera en que el CIADI tramita sus procedimientos. En consecuencia, el Ecuador apoya la propuesta de designar como archivo a la CPA.

44. El **Sr. Lebedev** (Federación de Rusia) dice que, había cuenta del consenso aparente de que la CNUDMI sería el archivo más adecuado, es esencial obtener lo antes posible los recursos financieros que le permitan desempeñar esa función. En toda decisión de la Comisión que se someta a la Asamblea General de las Naciones Unidas se deberá resaltar ese objetivo. Entre tanto, la Comisión debe adoptar una decisión entre dos instituciones internacionales de gran reputación. El orador recuerda que en 1976, cuando se estaba elaborando el Reglamento de Arbitraje, el alivio de la Comisión fue muy grande cuando para su aplicación se logró el apoyo de la CPA. Como a lo largo de los años la CPA ha prestado servicios invaluable, la Federación de Rusia está en favor de la designación de la CPA como archivo hasta el momento en que se cuente con fondos para transferir esa función a la CNUDMI. Obviamente, la CPA deberá mantener un

contacto estrecho con la secretaria de la CNUDMI mientras desempeñe las funciones asignadas.

45. **El Presidente** dice que considera que la Comisión conviene en que en el informe se deberá destacar el consenso de la Comisión en que la secretaria de la CNUDMI desempeñe la función de archivo y que se designa un archivo alternativo únicamente con miras a contar con un resguardo temporal, si fuera necesario.

46. *Así queda acordado.*

47. **El Presidente** dice que en el informe también se señalará que la institución designada, cualquiera sea, deberá mantenerse en estrecho contacto con la secretaria de la CNUDMI y cooperar plenamente con ella.

48. La **Sra. Kobayashi-Terada** (Japón) dice que, en su opinión, el hecho de ser miembro de alguna de las instituciones candidatas carece de relevancia en el contexto actual.

49. Habida cuenta de la experiencia del CIADI en la esfera de la transparencia en los procedimientos de arbitraje y del útil motor de búsqueda que ha elaborado con ese fin, el Japón se inclina por apoyar la designación del CIADI como archivo.

50. El **Sr. Macdonald** (Reino Unido) dice que el Reino Unido no hará suya ninguna declaración en el informe que indique el posible apoyo de la Comisión para la utilización de fondos del presupuesto ordinario para financiar el archivo.

51. El **Sr. Yuprasert** (Tailandia) expresa su apoyo a la designación de la CPA debido a los cargos ligeramente más reducidos que cobraría a las partes en una controversia.

52. El **Sr. Schöll** (Suiza) dice que Suiza tiene una leve preferencia por que se designe al CIADI como archivo temporal por tres razones: la base de datos del CIADI permite realizar búsquedas de texto completo en las bases de datos tanto de la jurisprudencia de la CNUDMI como del CIADI; el CIADI ha adquirido una experiencia considerable porque tramita un 70% de las causas conocidas en materia de inversiones; y el CIADI también tiene experiencia en la esfera de la transparencia en los procedimientos de arbitraje en materia de inversiones.

53. El **Sr. Agrawal** (India) expresa su preferencia por que se designe como archivo a la CPA.

54. El **Sr. Apter** (Israel) dice que, cualquiera sea la entidad designada, no solo deberá cooperar con la secretaria de la CNUDMI. La Comisión debe recomendar que esas dos instituciones también cooperen entre sí en

interés de las mejores prácticas en el ámbito de la transparencia.

55. La elección de la institución debe basarse en consideraciones técnicas, no políticas. Como en la actualidad el CIADI es la que más experiencia tiene en cuestiones relacionadas con la transparencia, la Comisión debería aprovechar esos conocimientos cuando designe un archivo temporal.

56. **El Presidente** dice que cree entender que la Comisión desea recomendar que las tres instituciones -CNUDMI, CIADI y CPA- cooperen en los asuntos relacionados con la transparencia, que se está convirtiendo en un aspecto muy importante del arbitraje en materia de inversiones.

57. *Así queda acordado.*

58. El **Sr. Räftegård** (Observador de Suecia) dice que es importante velar por que el público en general tenga fácil acceso al material, por ejemplo, permitiendo realizar búsquedas en los documentos de la CNUDMI y del CIADI sobre jurisprudencia. En consecuencia, Suecia expresa su preferencia por que se designe al CIADI como archivo temporal.

59. El **Sr. Hirsch** (Argentina) y la **Sra. Laborte-Cuevas** (Filipinas) expresan su apoyo a la designación de la CPA como archivo temporal.

60. El **Sr. Lee Jae Min** (República de Corea) dice que como la Comisión está entrando en un territorio inexplorado, la experiencia previa adquiere gran importancia. La posibilidad de contar con una función de búsqueda avanzada es una ventaja más. En consecuencia, la República de Corea se inclina por prestar apoyo a la designación del CIADI como archivo.

61. El **Sr. Snijders** (Observador de los Países Bajos) expresa su apoyo a la designación de la CPA como archivo en razón de la función que se le asignó en las versiones de 1976 y 2010 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

62. El **Sr. Möller** (Observador de Finlandia) dice que ambas instituciones están perfectamente capacitadas para asumir las funciones de archivo y Finlandia se sumará a la decisión de la mayoría.

63. El **Sr. Ghaniei** (República Islámica del Irán) pregunta cuántos fondos se necesitarán exactamente para que la CNUDMI pueda desempeñar las funciones de archivo. También desea saber si sería posible acelerar el proceso de financiación mediante la introducción de cargos obligatorios que pagarían las partes en una controversia y

creando un fondo de contribuciones voluntarias, además de solicitarse recursos con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

64. Si fuera necesario designar un archivo temporal, el Irán se inclinaría por la CPA.

65. **El Presidente** señala a la atención el documento A/CN.9/791, párrafos 5 a 10, en donde figura la estimación de los recursos necesarios. Según el párrafo 8, el presupuesto total del programa para el archivo en el primer bienio sería, sin incluir la tasa del 13% de apoyo a los proyectos, de 343.800 dólares y, en los bienios subsiguientes, de 493.600 dólares. Los cargos cobrados a las partes en la controversia no ayudarían a la CNUDMI, ya que se los depositaría con cargo al presupuesto general de las Naciones Unidas.

66. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que las contribuciones voluntarias se recaudarían por conducto del actual Fondo Fiduciario de la CNUDMI. Se establecería una cuenta secundaria a fin de que los fondos se puedan asignar para el funcionamiento del archivo.

67. El **Sr. Popkov** (Belarús) dice que, si bien Belarús reconoce la gran capacidad técnica del CIADI, apoya la designación de la CPA como archivo en razón de la experiencia adquirida a lo largo de varios decenios de arbitraje de controversias entre Estados, incluidas causas en materia de inversiones.

68. La **Sra. Cheng** (Singapur) dice que la CPA parece ser la elección preferible, porque ya tramita la gran mayoría de los arbitrajes en materia de inversiones con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, mientras que el CIADI lo hace aplicando su propio reglamento.

La sesión se suspende a las 11.25 horas y se reanuda a las 11.35 horas.

69. **El Presidente** dice que en el informe se señalará que algunas delegaciones han expresado la opinión de que toda solución dentro del sistema de las Naciones Unidas no deberá tener consecuencias para el presupuesto.

70. La **Sra. Rennie** (Reino Unido) dice que el Reino Unido, por razones técnicas y pragmáticas, ha decidido apoyar la designación de la CPA como archivo.

71. El **Sr. Möller** (Observador de Finlandia) dice que, tras reflexionar al respecto, Finlandia también ha decidido optar por la designación de la CPA.

72. El **Sr. Jacquet** (Francia) dice que, en las circunstancias actuales, parece preferible la designación de la CPA como archivo, en razón de su flexibilidad.

73. El **Sr. Jana Linetzky** (Observador de Chile) destaca la necesidad urgente de obtener los recursos que permitan a la CNUDMI desempeñar las funciones de archivo. Chile no desea expresar preferencia alguna entre las dos instituciones que voluntariamente se han ofrecido a desempeñar esas funciones.

74. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) agradece profundamente a los Estados, incluido Chile, que han adoptado medidas para asegurar los recursos extrapresupuestarios que permitirán a la CNUDMI actuar como archivo. En los últimos días se han logrado progresos considerables al respecto.

75. El **Sr. Kordač** (República Checa) expresa su apoyo a la designación de la CPA como archivo en razón de los cargos más reducidos que cobraría a las partes en una controversia y los tradicionales estrechos vínculos que existen entre la CPA y la CNUDMI.

76. El **Sr. Stoimenov** (Bulgaria) expresa su apoyo a la designación de la CPA por razones similares y porque esa institución prevé que la base de datos del archivo habrá de funcionar en los seis idiomas de trabajo de las Naciones Unidas.

77. El **Sr. Sikirić** (Croacia) dice que en las presentaciones a las Comisiones Quinta y Sexta de la Asamblea General se deberá destacar que la labor de la Comisión es de vital importancia para el estado de derecho en los planos nacional e internacional y que los estándares legislativos elaborados por la CNUDMI promueven el desarrollo sostenible.

78. El orador expresa su apoyo a la designación de la CPA como archivo.

79. **El Presidente** dice que considera que la Comisión apoya la propuesta del representante de Croacia respecto de las presentaciones a las Comisiones Quinta y Sexta.

80. *Así queda acordado.*

81. El **Sr. Kilppstein** (Alemania) dice que Alemania no desea expresar una preferencia respecto de la institución que deba actuar como archivo.

82. Sin embargo, señalando que en la carta que distribuyó entre las delegaciones el CIADI indicó cuatro puntos relativos al reglamento sobre la transparencia, el orador pregunta si esos puntos son condiciones previas para desempeñar temporalmente las funciones de archivo. Hace referencia en particular al requisito de que al reglamento se debe añadir una cláusula de exención de responsabilidad. Además, la sede del CIADI está en Washington y, en la actualidad, hay una cierta

intranquilidad respecto de la transmisión a los Estados Unidos de información delicada sin un sistema fiable de protección de datos. En consecuencia, pregunta si el CIADI cuenta con un régimen de protección de datos que satisfaga los estándares europeos.

83. La **Sra. Kinnear** (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) dice que los cuatro puntos no son condiciones previas para que el CIADI desempeñe las funciones de archivo. Se trata de cuestiones que habrá que abordar en algún momento, tal vez en las directrices, cualquiera sea el organismo que se desempeñe como archivo.

84. El CIADI cuenta con el sumamente efectivo muro de protección de datos establecido por el Grupo del Banco Mundial.

85. La **Sra. Le Duc Hanh** (Observadora de Viet Nam) expresa su preferencia por la CPA debido a su experiencia en tramitar no solo controversias en materia de inversiones, sino también en otros ámbitos, su experiencia en la gestión de bases de datos y su flexibilidad.

86. La **Sra. Escobar** (El Salvador) también expresa su preferencia por la CPA.

87. La oradora insta a los miembros de la Comisión a que alerten a las delegaciones de sus países en las Comisiones Quinta y Sexta de la Asamblea General acerca de la importancia de asegurar que, en su debido momento, la CNUDMI pueda estar en condiciones de desempeñarse como archivo.

88. **El Presidente** expresa su apoyo a esa recomendación.

89. El **Sr. Bittner** (Austria) expresa su preferencia por que se designe a la CPA como archivo.

90. **El Presidente** señala que una clara mayoría de los miembros ha expresado su preferencia por que se designe a la CPA como archivo temporal.

91. *Así queda acordado.*

92. **El Presidente** subraya que la decisión que se acaba de adoptar refleja un recurso de última instancia. Reitera el agradecimiento de la Comisión a ambas instituciones por sus ofrecimientos de apoyo.

93. El **Sr. Schneider** (Suiza) propone que la secretaría presente a la Comisión, en su próximo periodo de sesiones de 2014, un informe sobre la situación del establecimiento y funcionamiento del archivo.

94. *Así queda acordado.*

Proyecto de artículo 5 – Escritos presentados por partes en el tratado que no sean litigantes

95. **El Presidente** invita a la secretaría a que presente una propuesta de enmienda a la redacción del proyecto de artículo 5, párrafo 2.

96. La **Sra. Montineri** (Secretaría) observa que dos enmiendas ya habían sido propuestas por las delegaciones. Una es añadir las palabras siguientes al final del párrafo: “y la necesidad de evitar la presentación de escritos en que se apoye la reclamación de un inversionista de modo tal que pueda ser equivalente a protección diplomática”. La segunda propuesta es añadir la frase siguiente al final del párrafo: “Para evitar dudas, en el ejercicio de su discreción para permitir escritos de esa naturaleza, el tribunal arbitral tendrá en cuenta la necesidad de evitar la presentación de escritos en que se apoye la reclamación de un inversionista de modo tal que equivalga a protección diplomática”.

97. La secretaría ha tratado de combinar las dos propuestas. Sugiere que la frase siguiente se añada al final del párrafo 2: “y, a fin de evitar dudas, la necesidad de evitar la presentación de escritos en que se apoye la reclamación de un inversionista de modo tal que pueda ser equivalente a protección diplomática”.

98. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) propone reemplazar “a fin de evitar dudas” por “a fin de aportar una mayor certeza”. Expresa su apoyo a una propuesta anterior del representante del Canadá de suprimir las palabras “que no sean litigantes” y, además, propone reemplazar “que pueda ser equivalente a protección diplomática” por “que equivalga a protección diplomática”.

99. *Así queda acordado.*

100. El **Sr. Cachapuz de Medeiros** (Brasil) propone reemplazar “que equivalga a” por “que pueda interpretarse como que equivale a”.

101. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) dice que se opone a la enmienda porque la interpretación es un estándar indebidamente subjetivo.

102. El orador hace referencia al debate celebrado en una sesión anterior relativa al uso, en el artículo 4, párrafo 3, de la expresión “Para determinar si permite la presentación de un escrito”, y en el artículo 5, párrafo 2, de la expresión “En el ejercicio de su discreción para aceptar esos escritos”. Como en esta última expresión la referencia al ejercicio de discreción y, por consiguiente, al artículo 1, párrafo 4, podría complicar el proceso de examen, el orador propone que se la reemplace con la redacción utilizada en el artículo 4, párrafo 3.

103. El **Sr. Jacquet** (Francia) expresa su apoyo a esa propuesta.

104. El **Sr. Kordač** (Observador de la República Checa) dice que entiende que los factores mencionados en el artículo 1, párrafo 4, deben ser tenidos en cuenta por el tribunal arbitral cada vez que adopte una decisión que requiera el ejercicio de discreción, aun en los casos en que no se mencione expresamente la palabra “discreción”.

105. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) señala a la atención, en tal sentido, el párrafo 40 del informe del Grupo de Trabajo II (A/CN.9/760) relativo al artículo 4 (en ese entonces artículo 5).

106. **El Presidente** dice que el Grupo de Trabajo había convenido en que los factores pertinentes en el artículo 4, párrafo 3, eran los establecidos en el párrafo 3 y no los que figuran en el artículo 1, párrafo 4. Al enmendar el proyecto de artículo 5, párrafo 2, la Comisión aplicaría el mismo principio.

107. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) dice que no sugiere que se impida que el tribunal arbitral tenga en cuenta los factores del artículo 1, párrafo 4.

108. **El Sr. Kordač** (Observador de la República Checa) opina que la palabra “discreción” debe mencionarse en los párrafos pertinentes a fin de aclarar la cuestión. También debería usarse, por ejemplo, en el artículo 3, párrafo 3, en relación con la expresión “el tribunal arbitral podrá decidir”.

109. **El Presidente** dice que tiene entendido que los factores que se indican en el artículo 1, párrafo 4, son pertinentes toda vez que el tribunal ejerce su discreción, sin que importe que la palabra “discreción” aparezca o no en la norma en cuestión. Aplaza el debate sobre la cuestión hasta la sesión próxima.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (continuación)

Acta resumida de la 963ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena, Viena, el miércoles 10 de julio de 2013, a las 14.00 horas

[A/CN.9/SR.963]

Presidente: Sr. Moollan (Vicepresidente) (Mauricio)

Se declara abierta la sesión a las 14.30 horas.

Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado, en su forma enmendada.

Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación

- a) Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (continuación)** (A/CN.9/760, 765, 783, 787 y Add.1, Add.1/Corr.1, Add.2 y Add.3, y 793)

Proyecto de artículo 5 – Escritos presentados por partes en el tratado que no sean litigantes (continuación)

1. **El Presidente** invita a la Comisión a reanudar el debate acerca de si los factores enunciados en el artículo 1, párrafo 4, del reglamento sobre la transparencia son pertinentes cada vez que el tribunal arbitral ejerce su discreción. En el reglamento, la única referencia adicional a la discreción figura en el proyecto de artículo 5, párrafo 2. Después de las consultas oficiosas, se propone reemplazar la expresión “En el ejercicio de sus facultades discrecionales en cuanto a aceptar o no tales escritos” con “Para determinar si permite la presentación de tales escritos”, similar a la redacción del artículo 4, párrafo 3. En el informe se deberá reflejar el debate de la cuestión celebrado en la sesión precedente, haciéndose referencia, entre otras cosas, al pasaje del informe del Grupo de Trabajo II que se había citado (A/CN.9/760, párr. 40). Se deberá indicar que la Comisión convino en que el artículo 1, párrafo 4, es aplicable siempre que se solicite al tribunal que ejerza su discreción.

2. **El Presidente** señala que, de no escuchar objeciones, considerará que la Comisión conviene en esa propuesta.

3. *Queda aprobado el artículo 5, en su forma enmendada.*

4. *Queda aprobado el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre*

- b) Examen de instrumentos relativos a la aplicabilidad del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia a la solución de controversias surgidas en el marco de tratados de inversión ya existentes** (A/CN.9/765 y 784)

5. **El Presidente** señala a la atención el documento A/CN.9/784, sobre la aplicabilidad del Reglamento sobre la Transparencia de la CNUDMI a la solución de controversias surgidas en el marco de tratados de inversión ya existentes, que es un asunto de fundamental importancia, ya que existen más de 2.000 tratados bilaterales de inversión.

6. Se ha llegado al compromiso de que el Reglamento sobre la Transparencia se aplique a los arbitrajes en el marco de tratados futuros tramitados con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, a menos que las partes convengan en otra cosa. En el Grupo de Trabajo II también se llegó al entendimiento de que las partes que deseen aplicar el Reglamento sobre la Transparencia a los tratados ya existentes podrán hacerlo de distintas maneras, inclusive mediante una convención. Dicha convención se abriría a la ratificación por los Estados, pero estos no estarían obligados a ratificarla. Si tanto el Estado de origen como el del inversionista hubieran ratificado la convención antes de remitir la controversia a arbitraje, se presumiría que el tratado bilateral pertinente ha sido enmendado. En consecuencia, el ofrecimiento de arbitraje de la CNUDMI se transformaría en una oferta de arbitraje transparente. Por el contrario, si solo el Estado de origen hubiera ratificado la convención, no podría enmendar el tratado unilateralmente. Sin embargo, el Estado inversionista podría convenir en un arbitraje de la CNUDMI regido por la transparencia.

7. La Comisión tiene que decidir ahora si se debe encomendar al Grupo de Trabajo II que prepare una convención de esa naturaleza.

8. La **Sra. Kobayashi-Terada** (Japón) dice que tiene entendido que el Reglamento sobre la Transparencia solo se aplicaría cuando ambos Estados hubieran ratificado la convención.

9. **El Presidente** dice que la cuestión todavía se está debatiendo. El Grupo de Trabajo ha examinado si el derecho internacional público permite que la convención autorice a que el Estado de origen realice una oferta unilateral que tenga el efecto de enmendar el tratado bilateral de inversión, o que el Estado de origen pueda hacer una declaración en el sentido de que ha hecho esa oferta.

10. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) dice que es de vital importancia encomendar al Grupo de Trabajo II que elabore una convención que permita que el Reglamento sobre la Transparencia se aplique al gran número de tratados de inversión ya existentes.

11. El **Sr. Agrawal** (India) dice que el proyecto de artículo 3 de la convención propuesta no es coherente con el artículo 1, párrafo 2 del Reglamento sobre la Transparencia. En su opinión, la enmienda a un tratado bilateral o una declaración conjunta de las partes en el tratado es el mejor método para asegurar que el Reglamento de Arbitraje se aplique en los procedimientos de arbitraje tramitados en el marco de los tratados ya existentes.

12. **El Presidente** dice que no puede detectar incoherencia alguna, ya que el artículo 1, párrafo 2 b), del Reglamento sobre la Transparencia prevé la posibilidad de que las partes en un tratado convengan en la aplicación del Reglamento después de una fecha determinada. En todo caso, esas cuestiones las podría examinar el Grupo de Trabajo II, si se le encomendara la tarea propuesta.

13. El **Sr. Brown** (Unión Europea) dice que la convención propuesta ha despertado gran interés en la Unión Europea. La propuesta todavía se está debatiendo y en su debido momento se plantearán cuestiones de redacción y de otra índole.

14. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) expresa su firme apoyo a la elaboración de la convención propuesta.

15. **El Presidente** dice que la idea es crear un instrumento opcional (*opt-in*) que no imponga limitaciones a los Estados que por el momento no se sientan en condiciones de hacer suyo el Reglamento sobre la Transparencia. Es consciente de la preocupación de algunos Estados de que, una vez que exista una convención, se les presione para que la ratifiquen. Sugiere que se indique en

el informe que la Comisión no emitirá juicio de valor alguno sobre si un Estado ha ratificado o no la convención.

16. El **Sr. Schöll** (Suiza) dice que la redacción de un instrumento bilateral que permita la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia a los tratados ya existentes es el lógico paso siguiente para quienes quieren demostrar un compromiso verosímil respecto de la transparencia en los arbitrajes de inversión. Suiza acogería complacida una convención referida no solo a los arbitrajes de la CNUDMI, sino también a los arbitrajes tramitados en el marco de las normas de instituciones específicas. Señalando que algunos Estados cuentan con abultadas carteras de tratados bilaterales de inversión, dice que no se debería impedir a dichos Estados aplicar el Reglamento sobre la Transparencia de manera eficiente a la totalidad de su cartera. Por otro lado, conviene en que no se los debería obligar a hacerlo si consideraran que todavía no estuvieran dadas las condiciones para proceder de esa manera.

17. Suiza no solo está dispuesta a participar en debates, sino también a celebrar negociaciones oficiales respecto de la convención propuesta. El orador pregunta si dichas negociaciones podrían celebrarse en la Comisión, más que en el Grupo de Trabajo II, a fin de que el texto pueda presentarse más rápidamente a la Asamblea General para su aprobación oficial.

18. **El Presidente** dice que es su intención formular esa pregunta a la Comisión en el momento oportuno.

19. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) dice que Singapur es renuente a prestar apoyo a una convención. Ya señaló a la atención la cuestión de las costas. El Grupo de Trabajo II no ha resuelto de qué manera se verían afectadas las solicitudes de documentos después de que el tribunal arbitral hubiera concluido sus funciones, cuestión que también destacó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en su carta a la secretaría.

20. El equilibrio establecido en el artículo 1 del Reglamento sobre la Transparencia es muy delicado y el compromiso así logrado no es perfecto. Una convención tal vez alteraría ese equilibrio, y los Estados con reservas respecto del compromiso no tendrían que verse obligados a hacer suyo ese instrumento. Se deberá adoptar un criterio equilibrado hasta el momento en que haya una mayor claridad respecto del funcionamiento del Reglamento sobre la Transparencia y sus consecuencias en las costas.

21. **El Presidente** dice que los Estados que tuvieran preocupaciones como las mencionadas por el representante de Singapur podrían simplemente decidir no ratificar la

convención. Reitera que no se emitirían juicios de valor en tales casos.

22. La idea de preparar una convención fue parte de los debates desde un comienzo. El artículo 1, párrafo 2, se redactó específicamente teniendo en cuenta la posibilidad de permitir, tanto a las partes en una controversia como a las altas partes contratantes que así lo desearan, enmendar sus tratados bilaterales de inversión a fin de hacer aplicable el Reglamento sobre la Transparencia. Los Estados con grandes carteras de tratados tendrán que celebrar debates con un gran número de contrapartes o bien simplemente ratificar un instrumento único.

23. La **Sra. Escobar** (El Salvador) dice que la preparación de una convención es una tarea compleja que ocasionará demoras, también en cuanto al tiempo que necesitaría el Parlamento de su país para completar el proceso de ratificación. El Salvador no se opone a la convención, pero considera que se debería establecer un plazo a fin de que los Estados puedan comenzar a aplicar el Reglamento sobre la Transparencia lo antes posible.

24. La oradora propone que la Comisión se ocupe de la recomendación que insta a las partes en tratados de inversiones a que apliquen el Reglamento sobre la Transparencia a los tratados ya existentes.

25. El **Sr. Klippstein** (Alemania) dice que Alemania podría apoyar un mandato redactado cuidadosamente relativo a la convención. Sin embargo, propone que, como alternativa para los Estados que no están plenamente convencidos de los beneficios de la convención, se añada una referencia a una recomendación o a cláusulas modelo.

26. **El Presidente** sugiere que la Comisión examine la recomendación propuesta en el documento A/CN.9/784 y considere si en la decisión que se apruebe en la sesión siguiente se deberá incluir una referencia a dicha recomendación.

27. El **Sr. Apter** (Israel) dice que tiene entendido que la recomendación se había modificado a la luz de la solución de compromiso. De no haber sido así, habrá que continuar los debates.

28. Israel no opone reparos a que se encomiende al Grupo de Trabajo II que prepare una convención. Sin embargo, como el Reglamento sobre la Transparencia acaba ser aprobado, propone que la convención comience a examinarse en el período de sesiones de febrero de 2014, más que en el de septiembre de 2013, a fin de que los Estados tengan tiempo para celebrar consultas. Es claro que el objetivo último es convencer al mayor número posible de Estados a que ratifiquen la convención.

29. El **Sr. Jacquet** (Francia) dice que, según el artículo 1, párrafo 2 b), del Reglamento sobre la Transparencia, este solo se aplicará si las partes han convenido en su aplicación. La convención propuesta es solo un modo de expresar la intención de los Estados de aplicar el Reglamento a la solución de controversias surgidas en el marco de tratados concertados antes de la entrada en vigor del Reglamento. En consecuencia, Francia presta su apoyo a que se encomiende al Grupo de Trabajo II la preparación de una convención de esa naturaleza.

30. Las delegaciones que no respaldan la aplicación del Reglamento a la solución de controversias surgidas en el marco de los tratados de inversión ya existentes pueden permanecer indiferentes, ya que nada tienen que temer, o bien actuar con amplitud de miras y tal vez en su debido momento se persuadan del valor de la convención.

31. El **Sr. Li Wenzhu** (China) dice que, en la opinión de China, la convención propuesta es una medida prematura. Si bien el Presidente ha dicho que no se emitirá juicio de valor alguno contra los Estados que no ratifiquen la convención, sin duda se ejercerá presión contra ellos. Además, como el número de miembros de la CNUDMI es limitado, podría quedar comprometida la universalidad de la convención.

32. El **Sr. Lee Jae Min** (República de Corea) dice que considera importante que se encomiende al Grupo de Trabajo II la preparación de una convención. Sin embargo, recién se ha aprobado el Reglamento sobre la Transparencia y se necesita que transcurra un cierto tiempo para poder evaluar su aplicación en la práctica. La experiencia así adquirida podría ser útil en la redacción de la convención. Además, no se impide a los Estados que deseen aplicar el Reglamento a los tratados bilaterales de inversión ya existentes que así procedan, por lo que no es necesario actuar con apresuramientos indebidos en la preparación de la convención.

33. **El Presidente** dice que la convención simplemente modificaría tratados bilaterales de inversión. La experiencia en la aplicación del Reglamento tal vez influya en la decisión de un Estado de ratificarla, pero no ve qué consecuencias podría tener en el proceso de preparación.

34. El **Sr. Lee Jae Min** (República de Corea) dice que la existencia de una convención podría cambiar la dinámica de la negociación o interpretación de los tratados bilaterales de inversión.

35. **El Presidente** dice que comprende el temor de varias delegaciones de que, una vez que exista una convención, se ejerza presión sobre los Estados para que se adhieran a

ella. La manera más productiva de encontrar una solución que satisfaga a todos los interesados es que en el informe se incluya un claro mensaje que disipe esos temores.

36. La **Sra. Kobayashi-Terada** (Japón) dice que el Japón está dispuesto a prestar su apoyo a una decisión de consenso que encomiende al Grupo de Trabajo II la preparación de una convención. Sin embargo, como no está segura de si la aprobación de una convención de esa naturaleza es el criterio más eficiente y eficaz en relación con los costos, desea mantener abiertas otras opciones, como la aprobación de una recomendación en que se inste a las partes en tratados de inversión a aplicar el Reglamento.

37. El **Sr. Lebedev** (Federación de Rusia), señala que el objetivo básico es asegurar la aplicación amplia y rápida del Reglamento sobre la Transparencia, y pone de relieve la observación sobre el proyecto de artículo 1 de la convención propuesta que figura en el párrafo 6 del documento A/CN.9/784, en donde se indica que la convención solo se aplicará cuando el Estado de origen del inversionista y el Estado demandado sean también partes en ella. En consecuencia, si el Estado demandado hubiera ratificado la convención y el Estado inversionista no lo hubiera hecho, no se habría logrado el objetivo de promover la aprobación rápida del Reglamento sobre la Transparencia.

38. El orador considera que, en tal sentido, tal vez sea más efectiva la aprobación del proyecto de recomendación que figura en el documento A/CN.9/784 como iniciativa separada o en combinación con los proyectos de modelos de declaraciones interpretativas conjuntas o unilaterales. Quizás no sea prudente aprobar una convención antes de haber tenido cierta experiencia práctica en la aplicación del Reglamento. El proyecto de texto podría enmendarse teniendo en cuenta dicha experiencia.

39. **El Presidente** conviene en que los distintos métodos propuestos en el documento A/CN.9/784 no se excluyen mutuamente. A la brevedad se habrá de adoptar una decisión sobre el proyecto de recomendación y no es necesario adoptar medidas prácticas sobre los proyectos de modelos de declaraciones interpretativas conjuntas o unilaterales.

40. El **Sr. Möller** (Observador de Finlandia) señala que una recomendación tendrá un efecto mucho más limitado que una convención. Como también considera que toda demora en la preparación de una convención simplemente creará complicaciones, se pronuncia en favor de encomendar al Grupo de Trabajo II que comience el

proceso de preparación en el período de sesiones de septiembre de 2013.

41. La **Sra. Laborte-Cuevas** (Filipinas) expresa reservas acerca de la conveniencia de preparar una convención tan pronto como se apruebe el Reglamento sobre la Transparencia. Propone que el proceso de redacción se aplase hasta febrero o septiembre de 2014.

42. **El Presidente** señala que hay una clara mayoría en favor de la preparación de una convención, pero que varios Estados han expresado preocupación al respecto. Sugiere que, durante la pausa para consultas, se haga un esfuerzo por reducir las diferencias entre las opiniones de las delegaciones.

43. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) impugna la afirmación del Presidente de que hay una clara mayoría en favor de la preparación de una convención.

44. **El Presidente** dice que el representante de Singapur tiene derecho a esa opinión. Sin embargo, está convencido de que, si se encarase la cuestión con una visión de conjunto, se podría llegar a un compromiso que proteja los intereses de todas las partes.

Se suspende la sesión a las 15.35 horas y se la reanuda a las 16.35 horas.

45. **El Presidente** dice que se ha redactado el mandato que se encomendará al Grupo de Trabajo II. Tiene entendido que se ha conseguido el apoyo provisional de la mayoría de los Estados que expresaron preocupación acerca de la convención. Invita a la Comisión a tomar nota del proyecto, que se debatirá en la sesión siguiente:

“La Comisión confía al Grupo de Trabajo la tarea de preparar una convención relativa a la aplicación a los tratados existentes del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado, teniendo en cuenta que el propósito de la convención es dar a los Estados que desean que el Reglamento sobre la Transparencia sea aplicable a sus tratados existentes un mecanismo eficiente con ese fin, sin que se cree ninguna expectativa en el sentido de que otros Estados utilizarán el mecanismo ofrecido por la convención.”

46. **El Presidente** dice estar convencido de que, si el mandato se encomendara en esos términos, durante el proceso de redacción se podrían alcanzar compromisos respecto de cuestiones como la redacción del preámbulo, el número de ratificaciones necesarias para la entrada en vigor de la convención y el alcance de las reservas.

Subraya que todavía no se ha trabajado en el proyecto de convención que la Comisión tiene actualmente ante sí (A/CN.9/784). Se trata simplemente de una propuesta de la secretaría.

47. El **Presidente** invita a la Comisión a examinar el proyecto de recomendación que figura en el párrafo 20 del documento A/CN.9/784. Propone que los párrafos de la parte dispositiva se incluyan en la decisión de la Comisión en que se aprueba el Reglamento, que luego se incorporarían en la resolución de la Asamblea General.

48. El **Sr. Apter** (Israel) propone que en el párrafo 1, después de la expresión “un mayor grado de transparencia”, se añada la expresión “los Estados examinen la posibilidad de aplicar” o, como alternativa, “los Estados consideren la aplicación del”, y se suprima la expresión “se aplique”.

49. El **Sr. Magraw** (Center for International Environmental Law) expresa su oposición a la enmienda propuesta. La Comisión ha encomendado al Grupo de Trabajo II que asegure la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados, que en su mayoría surgirán en el marco de tratados ya existentes. Si se aprobara la modificación propuesta, se podría interpretar que la Comisión está dando marcha atrás.

50. La **Sra. Montineri** (Secretaría) dice que el objetivo de la recomendación es promover la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia. Sin embargo, los Estados están en libertad de adoptar la decisión que

consideren adecuada. La oradora expresa sus reservas a que se incluya la redacción propuesta por el representante de Israel en una decisión de la Comisión que posteriormente pasaría a ser una resolución de la Asamblea General.

51. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) dice que prefiere que se mantenga la redacción original.

52. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) expresa su apoyo a la propuesta del representante de Israel, la cual, en su opinión, no deja de adecuarse a las instrucciones dadas por la Comisión al Grupo de Trabajo II.

53. El **Sr. Apter** (Israel) dice que no insistirá en la modificación propuesta si esta no recibiera un apoyo suficiente. Sin embargo, propone que en la recomendación se destaque el compromiso alcanzado respecto del artículo 1, párrafo 2, del Reglamento sobre la Transparencia.

54. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) propone que en el párrafo 1 se reemplace la expresión “fecha de adopción” con “fecha de entrada en vigor”, que es la usada en el párrafo 1, párrafo 2 b) del Reglamento.

55. *Así queda acordado.*

56. *Queda aprobado el párrafo 1 de la recomendación, en su forma modificada.*

Se levanta la sesión a las 17.05 horas.

Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado
(continuación)

**Acta resumida de la 964ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
Viena, el jueves 11 de julio de 2013, a las 9.30 horas**

[A/CN.9/SR.964]

Presidente: Sr. Moollan (Vicepresidente) (Mauricio)

Se declara abierta la sesión a las 10.20 horas.

Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación

b) Examen de instrumentos relativos a la aplicabilidad del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia a la solución de controversias surgidas en el marco de tratados de inversión ya existentes (A/CN.9/765 y 784)

1. El **Presidente** señala el siguiente texto, propuesto en la sesión anterior en relación con el mandato que la Comisión encomendaría al Grupo de Trabajo II:

“La Comisión confía al Grupo de Trabajo la tarea de preparar una convención relativa a la aplicación a los tratados existentes del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado, teniendo en cuenta que el propósito de la convención es dar a los Estados que desean que el Reglamento sobre la Transparencia sea aplicable a sus tratados existentes un mecanismo eficiente con ese fin, sin que se cree ninguna expectativa en el sentido de que otros Estados utilizarán el mecanismo ofrecido por la convención.”

2. El **Sr. Galindo** (Ecuador) propone la siguiente variante, redactada en consulta con otras delegaciones:

“La Comisión confía al Grupo de Trabajo el mandato de preparar una convención para facilitar la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia teniendo en cuenta las preocupaciones de algunos Estados respecto de las dificultades que podría plantear la aplicación inmediata del Reglamento sobre la Transparencia a los tratados existentes.”

3. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) dice que su delegación no puede apoyar esa propuesta porque en ella se recoge la posición de un solo grupo de Estados, en tanto que el texto propuesto en la sesión anterior se hace eco de las opiniones de los dos bandos.

4. El **Sr. Jacquet** (Francia) opina que el texto modificado no es equilibrado, en la medida en que se concentra en los riesgos que puede entrañar una

convención encaminada a dotar a los Estados que desean que el Reglamento sea aplicable a sus tratados existentes de un mecanismo eficiente con ese fin.

5. El **Sr. Brown** (Unión Europea), el **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) y el **Sr. Schöll** (Suiza) se suman a las observaciones formuladas por los delegados del Canadá y Francia.

6. La **Sra. Liang Danni** (China) dice que el Grupo de Trabajo II debería tener en cuenta las preocupaciones expresadas por algunos Estados con respecto a la aplicación inmediata del Reglamento a los tratados existentes.

7. El **Presidente** indica que en el informe se hará notar que el texto propuesto por el delegado del Ecuador ha obtenido el apoyo de varias delegaciones.

8. El **Sr. Apter** (Israel) destaca la importancia de velar por que el Grupo de Trabajo II tenga presente la definición de su mandato, propuesto en la sesión anterior.

9. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) dice que su delegación está dispuesta a hacer suyo el texto propuesto en la sesión anterior.

10. El **Presidente** dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el texto del mandato del Grupo de Trabajo II que se propuso en la sesión anterior.

11. *Así queda acordado.*

a) Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado
(continuación) (A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.1 y 2; A/CN.9/XLVI/CRP.2/Add.1; y A/CN.9/XLVI/CRP.3)

12. El **Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre la parte del proyecto de informe que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.1.

13. El **Sr. Apter** (Israel) propone que se suprima la última oración del párrafo 9, que no recoge las deliberaciones de la Comisión. El texto de la oración es el

siguiente: “Se convino en que no hacía falta aplicar esa distinción cuando se trataba de arbitrajes entablados con arreglo a otros reglamentos o de carácter especial”.

14. **El Presidente** propone que esa oración se modifique de la siguiente manera: “Se convino en que habría que tener en cuenta otras cuestiones cuando se tratara de arbitrajes entablados con arreglo a otros reglamentos o de carácter especial”.

15. *Así queda acordado.*

16. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) propone que en la versión inglesa, en la última oración del párrafo 10 se sustituya “*under other sets of arbitration rules or ad hoc*” por “*under other sets of arbitration rules or in ad hoc proceedings*”.

17. *Así queda acordado.*

18. El **Sr. Brown** (Unión Europea) propone que en el párrafo 13 se sustituya la frase “en el que la responsabilidad podía atribuirse a diferentes partes en el tratado, y que, en consecuencia, una parte pertinente no tenía por qué ser necesariamente solo el Estado de origen del inversionista”, por el siguiente texto: “en los que podía ser difícil identificar a las ‘partes pertinentes’ y resultaría más sencillo usar el criterio del ‘Estado demandado’. En consecuencia, se decidió conservar la expresión ‘Estado demandado’”.

19. *Así queda acordado.*

20. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) propone que en el párrafo 21 se sustituya la frase “en el reglamento se debía requerir siempre que el tribunal arbitral celebrara tales consultas” por “que si se contemplaba que el tribunal arbitral celebrara tales consultas debía señalarse explícitamente en el reglamento”.

21. *Así queda acordado.*

22. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) dice que el propósito del párrafo 29 es indicar cómo debe actuar el archivo en caso de desacuerdo con respecto a los procedimientos de transparencia. Por lo tanto, propone que se añada la siguiente oración: “El tribunal arbitral resolvería entonces cualquier desacuerdo que surgiera entre las partes litigantes antes de que se enviaran más documentos al archivo”.

23. *Así queda acordado.*

24. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) propone que se añada la frase “en la que debieran suprimirse partes del texto” después de “documentación” y que se sustituya “arbitrajes en materia de inversiones” por “actuaciones arbitrales”.

25. *Así queda acordado.*

26. *Queda aprobado el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.1 en su forma enmendada.*

27. **El Presidente** invita a formular observaciones sobre el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.2.

28. El **Sr. Popkov** (Belarús) propone ampliar el párrafo 14 añadiéndole el siguiente texto: “ya que la naturaleza jurídica del procedimiento de protección diplomática y de la presentación de escritos por las partes en el tratado no litigantes es diferente. El problema puede estar relacionado no con el ejercicio de la protección diplomática sobre la base del artículo 5, sino con la posible utilización de esas disposiciones para proteger de manera persistente e indebida el derecho de un inversionista en virtud del tratado”.

29. **El Presidente** opina que una solución más sencilla sería reformular el párrafo 14 de la siguiente manera: “Se aclaró que el propósito no era que el artículo 5 se utilizara de un modo que equivaliera al ejercicio de la protección diplomática”. El orador no recuerda que se haya deliberado acerca de la protección de los inversionistas de manera indebida y persistente, razón por la cual considera que la nueva oración propuesta por el representante de Belarús no se puede incluir en el informe. Propone la siguiente variante: “Una delegación puso de relieve el hecho de que la protección diplomática era un concepto distinto que no podía aplicarse con arreglo al artículo 5 y que existía el riesgo de que esas disposiciones se utilizaran para proteger de manera indebida y persistente el derecho de un inversionista en virtud del tratado”. El orador invita a la Comisión a que considere la posibilidad de redactar un texto análogo durante la pausa que se hará para celebrar consultas.

30. *Así queda acordado.*

31. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) hace referencia a la siguiente oración del párrafo 19: “se aclaró que el principio enunciado en el párrafo 1 era que las audiencias debían ser públicas”. Propone que se sustituya “las audiencias debían ser públicas” por “las audiencias son públicas”.

32. *Así queda acordado.*

33. El **Sr. Apter** (Israel), en relación con el párrafo 31, desea saber si en el título oficial del Reglamento sobre la Transparencia debería figurar el año en que se aprobó.

34. La **Sra. Montineri** (Secretaría) dice que la fecha se incluirá cuando el Reglamento se publique en el sitio web de la CNUDMI. Sin embargo, no es la práctica habitual incluirla en el título oficial, especialmente porque el instrumento se aprobará antes de entrar efectivamente en vigor.

35. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) propone que antes de la segunda oración del párrafo 32 se inserte la siguiente oración: “La Comisión observó que la forma de presentación del Reglamento sobre la Transparencia no afectaría a su ámbito de aplicación conforme al artículo 1”. La siguiente oración comenzaría entonces con las palabras “Asimismo observó que”.

36. *Así queda acordado.*

37. El **Presidente** señala que el párrafo 14 es el único párrafo del documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.2 que aún no se ha aprobado.

38. Se invita a formular observaciones sobre el documento A/CN.9/XLVI/CRP.2/Add.1, en que figura la versión modificada del Reglamento sobre la Transparencia.

39. El **Sr. Klippstein** (Alemania) propone que en el artículo 1, párrafo 2, se sustituya “Con respecto a los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI,” por “Con respecto a los arbitrajes entre inversionistas y Estados”.

40. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) propone como variante “Con respecto a un arbitraje entre inversionistas y Estados”.

41. El **Presidente** sugiere que se conserve el texto original porque confirma que las disposiciones subsiguientes son aplicables a todos los arbitrajes.

42. *Así queda acordado.*

43. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América), en relación con la modificación del artículo 1, párrafo 4, del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, señala que la remisión entre corchetes a la versión más breve del título del Reglamento sobre la Transparencia es innecesaria si este se menciona una sola vez.

44. El **Presidente** indica que el documento A/CN.9/XLVI/CRP.2/Add.1 queda aprobado, salvo en lo que respecta al artículo 5, párrafo 2, y al artículo 8, que se examinarán más adelante.

45. Se invita a formular observaciones sobre el documento A/CN.9/XLVI/CRP.3, en que figura el proyecto de decisión de la Comisión relativo a la aprobación del Reglamento sobre la Transparencia. Posteriormente se añadirá otro párrafo relacionado con la recomendación sobre la aplicación del Reglamento a la solución de controversias surgidas en el marco de tratados de inversión ya existentes.

46. El **Sr. Brown** (Unión Europea) propone que en el párrafo 4, después de “recomienda a todos los Estados” e “invita a los Estados”, se añada “y otras entidades” o “y organizaciones regionales de integración económica”.

47. La **Sra. Kobayashi-Terada** (Japón) propone que la palabra “Estados” se sustituya en ambos casos por “partes en los tratados internacionales de inversión”.

48. La **Sra. Montineri** (Secretaría) dice que la decisión en su conjunto está dirigida a los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, la invitación de la segunda parte del párrafo final está dirigida básicamente a las altas partes contratantes en los tratados.

49. El **Presidente** entiende que la Comisión desea que en el párrafo 4 se sustituya “invita a los Estados” por “invita a las partes en los tratados internacionales de inversión”.

50. *Así queda acordado.*

51. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) propone que en el párrafo 1 de la versión inglesa se suprima la coma después de “*UNCITRAL Arbitration Rules*” y que en el párrafo 3 de la misma versión se suprima el artículo indefinido antes de “*new article 1*”.

52. *Así queda acordado.*

Se suspende la sesión a las 11.30 horas y se reanuda a las 12.05 horas.

53. El **Sr. Schneider** (Suiza) propone que en la versión inglesa se modifique el comienzo del párrafo 4 de la decisión de la siguiente manera, según la formulación utilizada en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI: “*Recommends the use of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration*”.

54. *Así queda acordado.*

55. El **Presidente** invita a la Comisión a que reanude el examen del párrafo 14 del documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.2. Se ha propuesto el siguiente texto: “En relación con el párrafo 2, se aclaró que no se había pretendido que mediante esa disposición se permitiera la presentación de escritos en los que se apoyara la reclamación de un inversionista de modo tal que equivaliera a protección diplomática. Una delegación opinó que la palabra ‘equivaler’ podría no servir de orientación suficiente al tribunal arbitral”.

56. El **Sr. Schneider** (Suiza) propone añadir que la Comisión no comparte esa opinión.

57. El **Presidente** propone que se añada la siguiente oración: “Esa opinión no fue respaldada”.

58. De no haber objeciones, se entenderá que la Comisión desea aprobar el párrafo 14 y el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.2 en su conjunto en su forma enmendada.

59. *Así queda acordado.*

Labor futura en materia de solución de controversias comerciales (A/CN.9/785)

60. **El Presidente** señala a la atención de la Comisión el documento A/CN.9/785, relativo a la labor futura. Como no se adoptará ninguna decisión al respecto hasta el final del período de sesiones, el propósito es, en esos momentos, llegar a un acuerdo sobre el orden de prioridades. Cabe entender que se dará alta prioridad a la revisión de las Notas de la CNUDMI sobre la Organización del Proceso Arbitral.

61. En una mesa redonda con los profesionales del arbitraje que se celebró en París en abril de 2012, organizada conjuntamente por la secretaría y el Instituto de Arbitraje Internacional, se planteó la posibilidad de que la CNUDMI considerara suspender sus actividades normativas por el momento, a menos que pudiera determinar un sector en el que disponer de nuevas normas fuera realmente de utilidad para el sector del arbitraje. La CNUDMI ha producido un notable acervo de normas, pero los recursos tal vez podrían aprovecharse más en esos momentos si se utilizaran para crear capacidad con miras a lograr que esas normas se aplicaran debidamente. Esa opinión fue apoyada por un gran número de participantes en la mesa redonda.

62. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) señala una cuestión que suscita gran preocupación en los círculos del arbitraje en la esfera de las inversiones. Como la mayoría de los tratados permiten que no solo la empresa por la que se encauza la inversión, sino también sus accionistas, incluidos los accionistas indirectos, entablen un procedimiento de arbitraje para resarcirse de los daños sufridos, puede haber varios procedimientos paralelos relacionados con los mismos daños económicos y, en algunos casos, demandas superpuestas. Una cuestión conexa es que pueden iniciarse procedimientos de arbitraje contractual que entrañen demandas de indemnización, paralelamente a procedimientos de arbitraje sobre inversiones, en relación con los mismos daños económicos. Todavía no hay un sistema que pueda utilizarse para restablecer el orden en tales casos. En noviembre de 2013 se celebrará una conferencia sobre esa cuestión, en la que participarán universitarios y profesionales del arbitraje. A juicio de la oradora, aún no ha llegado el momento para emprender una actividad normativa.

63. Otra cuestión compleja que ha de examinarse multilateralmente son los procedimientos paralelos de arbitraje civil comercial en que intervienen tribunales judiciales y tribunales arbitrales. Al respecto, existen normas claras en la mayoría de los regímenes de procedimiento civil internacional, entre ellos el Reglamento de Bruselas. Habida cuenta de la importancia que reviste en ese contexto el artículo II de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, tal vez sea

conveniente considerar la posibilidad de redactar un protocolo de la Convención en el futuro.

64. **El Presidente** pregunta si la labor realizada por la Asociación de Derecho Internacional sobre la doctrina de la litispendencia es útil al respecto.

65. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) dice que podría servir de punto de partida valioso para todo examen que deseara realizar la CNUDMI acerca de la cuestión.

66. La **Sra. Montineri** (Secretaría), en relación con el artículo 8 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, relativo a los acuerdos de arbitraje y las demandas sobre el fondo del litigio entabladas ante un tribunal, señala que el compendio sobre jurisprudencia relativa a la Ley Modelo pone de manifiesto enfoques divergentes.

67. **El Presidente** se pregunta si la Comisión podría adoptar medidas para promover la interpretación uniforme del artículo 8 de la Ley Modelo. Se plantea la cuestión de determinar si el tribunal, para decidir si va a paralizar las actuaciones arbitrales, debería proceder a un examen completo de la validez del acuerdo de arbitraje, o simplemente a un examen a primera vista.

68. El **Sr. Schöll** (Suiza) señala que, antes de encomendar una tarea al Grupo de Trabajo II, debe haber una indicación clara de que ningún otro foro institucional se esté ocupando ya de ese aspecto y esté en mejores condiciones para realizar el trabajo. La Comisión, por supuesto, debería seguir examinando el tema de los procedimientos paralelos en el arbitraje comercial. No obstante, el orador considera que es demasiado pronto para abordar la cuestión de la interpretación del artículo 8 de la Ley Modelo, o para redactar un protocolo de la Convención de Nueva York.

69. Habida cuenta de que la secretaría ha acumulado un gran caudal de conocimientos especializados en la esfera del arbitraje, la delegación del orador no se opondría a que se asignara a esta la tarea de actualizar las Notas sobre la Organización del Proceso Arbitral para después presentar un proyecto de texto directamente a la Comisión.

70. La **Sra. Montineri** (Secretaría) dice que la secretaría preferiría que el Grupo de Trabajo II dedicara un período de sesiones a la actualización de las Notas, ya que se necesita información sobre las prácticas actuales de arbitraje del mayor número posible de Estados.

71. El **Sr. Jacquet** (Francia) indica que su delegación no comparte el escepticismo expresado por el representante de Suiza respecto de la cuestión de los procedimientos paralelos. El orador no entiende por qué el Grupo de Trabajo II no debería abordar la cuestión y formular directrices para hacer frente a las dificultades prácticas que suelen presentar esas actuaciones.

72. Sin embargo, su delegación mostraría menos entusiasmo con respecto a cuestiones como la facultad del tribunal arbitral para determinar su propia competencia. El Grupo de Trabajo no debería emprender el examen de temas de derecho comparado. Debería ocuparse exclusivamente de cuestiones normativas.

73. El **Presidente** desea saber si la Comisión está de acuerdo en que el primer tema que habría que examinar

después de concluir la elaboración de la convención sobre la transparencia sería la actualización de las Notas sobre la Organización del Proceso Arbitral.

74. *Así queda acordado.*

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

**Acta resumida de la 965ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
Viena, el jueves 11 de julio de 2013, a las 14.00 horas**

[A/CN.9/SR.965]

Presidente: Sr. Moollan (Vicepresidente) (Mauricio)

Se declara abierta la sesión a las 14.15 horas.

**Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje
y la conciliación**

**c) Preparación de una guía sobre la Convención de
Nueva York de 1958 (A/CN.9/786)**

1. El **Presidente** invita a la secretaría a que presente el tema 4 c) del programa.

2. La **Sra. Montineri** (Secretaría) dice que la Comisión, en su 41º período de sesiones, celebrado en 2008, decidió sobre la base de un informe de la secretaría relativo a la aplicación de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (la Convención de Nueva York), pedir a la secretaría que estudiase la viabilidad de preparar una guía sobre la Convención de Nueva York. En ese informe de la secretaría, en el que se tuvieron en cuenta las observaciones formuladas por 108 Estados partes en la Convención, se señalaron problemas tanto de índole legislativa como judicial relacionados con la aplicación de la Convención. Algunos de esos problemas se deben a interpretaciones divergentes de sus disposiciones y otros a la falta de conocimiento de la Convención. Tras estudiar la cuestión a lo largo de un período de dos años, la secretaría ha decidido adoptar un criterio inclusivo que abarque la recopilación de la mayor cantidad posible de información sobre las decisiones dictadas en el marco de la Convención en una amplia gama de países de todo el mundo. Así pues, la información recopilada con la ayuda del Profesor Bermann, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, y del Profesor Gaillard, del Instituto de Estudios Políticos de París, ha sido publicada en Internet. Dicha información ha servido de base para la elaboración de una guía legislativa no vinculante sobre la Convención de Nueva York. La oradora insta a los Estados que todavía no han participado en el proyecto a que lo hagan, puesto que el objetivo es valerse del mayor número posible de colaboradores. Es de esperar que la guía se concluya antes del final de 2013 y se publique oportunamente.

3. En el documento A/CN.9/786 figura un extracto de la guía en lo que se refiere al artículo VII de la Convención de Nueva York, en el que se enumeran las diferentes

interpretaciones a que ha dado lugar dicho artículo. Si bien en la guía se respetan los diferentes criterios adoptados, también se pone de relieve el criterio que se reputa preferible a la luz de la labor preparatoria de la Convención.

4. La **Sra. Banifatemi** (Instituto de Arbitraje Internacional) hace referencia al sitio web (www.newyorkconvention1958.org) que se ha creado con el fin de divulgar la información recopilada en el marco de la preparación de la guía. Dicho sitio web se exhibe en una pantalla en la sala de conferencias. En una sección figura la guía sobre la Convención de Nueva York, desde el artículo I al artículo VII, siendo este último el que se aborda en el documento A/CN.9/786. Los demás artículos se examinarán a finales de 2013. En el sitio web se indica, respecto de cada artículo, la correspondiente labor preparatoria, seguida de un análisis. Asimismo, se proporcionan enlaces a jurisprudencia y documentos de libre acceso en Internet. La información recogida hasta la fecha abarca un total de 22 países y más de 1.000 causas, incluidas 900 decisiones en su idioma original, de las cuales se han traducido más de 100. La guía completa estará disponible en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

5. El sitio web dispone de una poderosa herramienta de búsqueda. Se pueden realizar búsquedas por país, en relación con cada uno de los 22 países comprendidos y también respecto de la Organización para la Armonización de la Legislación Empresarial en África (OHADA). La información se puede filtrar en función del tipo de tribunal, el idioma y el artículo de la Convención. Los datos se actualizan de forma permanente.

6. Se ha recibido una asistencia muy valiosa de los colaboradores, tanto individuales como institucionales, que se mencionan en el sitio web. Se espera que oportunamente se incorporen más países por esa misma vía.

7. El **Sr. Gaillard** (Instituto de Arbitraje Internacional) se suma a la oradora anterior al expresar su agradecimiento a todos los colaboradores que facilitan el proceso de seguimiento de la jurisprudencia y la tarea de determinar si existe consenso sobre ciertos aspectos. En los casos en que no existe consenso, se describen las tendencias de la manera más objetiva posible y se intenta indicar cuál es el

criterio más acorde con el espíritu de la Convención de Nueva York. En general, el criterio utilizado para la aplicación de la Convención es relativamente uniforme y solo en muy pocos casos se registra una divergencia notable respecto de los principios subyacentes.

8. El **Sr. Bermann** (Instituto de Arbitraje Internacional) dice que la guía constituye una labor en curso en muchos aspectos, y que ha aumentado la cantidad de países comprendidos y las actividades desarrolladas en el marco de esa labor. Es evidente que a medida que se incrementa el número de colaboradores, la tarea de coordinación se vuelve más difícil. Es necesario determinar distintas líneas de interpretación que permitan señalar cuál es la posición que más se ciñe al espíritu y el propósito de la Convención de Nueva York. En opinión del orador se trata de un proyecto del que la CNUDMI puede estar muy orgullosa.

9. **El Presidente** expresa, en nombre de la Comisión, su vivo agradecimiento a todos aquellos que han participado en la elaboración de la guía y del sitio web. Es evidente que, en este tipo de labor relacionada con la jurisprudencia de diversos países, se expresan opiniones. Por lo tanto, sugiere que se aclare en el informe que esas opiniones no constituyen el resultado de un consenso alcanzado en el seno de la Comisión.

10. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) pregunta qué rango tendrá la guía en caso de que se publique como documento de las Naciones Unidas. Si su publicación debe ser autorizada por la Comisión, cabe suponer que esta podrá aportar sus puntos de vista, si fuera necesario.

11. La **Sra. Montineri** (Secretaría) dice que la guía podría distribuirse entre los miembros de la Comisión antes de su publicación.

12. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) menciona, a manera de ejemplo, la Guía Jurídica de la CNUDMI sobre Transferencias Electrónicas de Fondos, que es el fruto de investigaciones realizadas por la secretaría en colaboración con una serie de grupos de expertos. Esa clase de publicaciones no requieren el mismo tipo de aprobación por parte de la Comisión que se exige para los documentos normativos. La Comisión podría dar su autorización para que la secretaría publique la guía, u optar tal vez por revisar el texto antes de autorizar su publicación.

13. El **Sr. Schöll** (Suiza) propone que, una vez finalizada, la guía se presente a la Comisión a fin de que esta pueda determinar su rango. La aprobación del texto por la Comisión reforzará su legitimidad.

14. **El Presidente** expresa dudas acerca del rango de la guía a pesar de su excelente calidad. Por ejemplo, las disposiciones del artículo VII de la Convención de Nueva York son sumamente controvertidas. Los autores prestan un valioso servicio al sector del arbitraje, pero, como se ha señalado, a veces expresan opiniones personales. Por lo tanto, **el Presidente** tiene importantes reservas acerca de la conveniencia de solicitar la autorización de la Comisión para la publicación de la guía.

15. La **Sra. Montineri** (secretaría) señala que la finalidad de la guía no es expresar opiniones, sino presentar la jurisprudencia y las tendencias actuales, sin emitir juicios de valor. Habida cuenta de que es importante elaborar un documento que sea aceptable para todos, la secretaría agradecerá toda observación que la ayude a lograr ese objetivo en los meses siguientes.

16. **El Presidente** dice que no es su intención dar a entender que los autores carecen de objetividad. Sin embargo, es imposible analizar si determinadas tendencias son compatibles con el espíritu de la Convención de Nueva York sin abrir juicio al respecto.

17. La **Sra. Kaufmann-Kohler** (Suiza) opina que sería extraño que no se permitiera a los autores de la guía, que son académicos muy prestigiosos, expresar sus opiniones. Dado que, como es natural, los Estados tienen opiniones distintas, basadas en precedentes judiciales divergentes, difícilmente se pueda esperar que aprueben posiciones doctrinales opuestas. La oradora sugiere que la Comisión pida a la secretaría que estudie la cuestión junto con los autores y presente una propuesta sobre el procedimiento que debería seguirse.

18. La **Sra. Perales Viscasillas** (España) manifiesta que su delegación comparte algunas de las dudas expresadas por los oradores anteriores. Asimismo, dice que participó en la actualización del Compendio de la CNUDMI sobre jurisprudencia relativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, tarea que también exigió mantener una postura neutral. El Compendio fue aprobado por la Comisión. La oradora se pregunta por qué no se ha utilizado en la elaboración de la guía la base de datos oficial de la serie CLOUT, que contiene jurisprudencia relativa a los textos de la CNUDMI.

19. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) observa que la cuestión de si la Comisión puede aprobar documentos que contengan opiniones doctrinales ya ha sido objeto de debate en varias ocasiones en relación, por ejemplo, con el Compendio sobre jurisprudencia mencionado por la representante de España, la Guía

Jurídica de la CNUDMI sobre Transferencias Electrónicas de Fondos, y demás guías y compendios. En 2008, la Comisión encargó a la secretaria que difundiera información sobre la interpretación judicial de la Convención de Nueva York.

20. Existen varias alternativas. La guía podría publicarse bajo la responsabilidad exclusiva de la secretaria. Una segunda posibilidad sería que la Comisión tomara nota de la publicación sin pronunciarse sobre su contenido. Una tercera alternativa consistiría en distribuir la guía, una vez finalizada, entre los Gobiernos a los efectos de que formulen observaciones para que la Comisión las examine en un futuro período de sesiones, pero en ese caso le sería más difícil a la Comisión desvincularse del contenido de la guía.

21. **El Presidente** dice que la segunda alternativa tal vez sea más conveniente. La Comisión podría tomar nota de la guía y fomentar su uso sin emitir juicio alguno sobre su contenido.

22. A la **Sra. Rennie** (Reino Unido) le preocupa que la publicación como un documento de la CNUDMI de una guía en la que se expresen las opiniones de sus autores implique de algún modo la aprobación de su contenido. La oradora propone aplazar la decisión sobre el procedimiento que habrá de adoptarse hasta tanto no se haya finalizado la guía.

23. **El Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) expresa su apoyo a la propuesta de la representante del Reino Unido.

24. **El Sr. Kordač** (Observador de la República Checa) sugiere que los autores aclaren cuáles son las partes de la guía en las que se expresan sus opiniones personales. De ese modo, el análisis de los autores podría publicarse por separado, como un compendio de jurisprudencia.

Labor futura en materia de solución de controversias comerciales (*continuación*) (A/CN.9/785)

25. **El Presidente** invita a formular más observaciones sobre la labor futura.

26. **El Sr. Lebedev** (Federación de Rusia) dice que está de acuerdo con los oradores que en la sesión anterior subrayaron la importancia del tema de los procedimientos paralelos en el ámbito del arbitraje en materia de inversiones, el cual debería incluirse en el programa del Grupo de Trabajo II. También apoya la propuesta de revisar las Notas de la CNUDMI sobre la Organización del Proceso Arbitral.

27. Además, debería asignarse prioridad al tema de la arbitrabilidad, ya que se plantean muchos problemas sui generis en ese contexto. Por último, el orador apoya la inclusión en el programa del Grupo de Trabajo II de la cuestión del arbitraje en demandas colectivas. La aplicación de un criterio comparativo a esa cuestión podría resultar de gran utilidad.

28. **El Sr. Kordač** (Observador de la República Checa) dice que la cuestión de los procedimientos paralelos es de gran importancia. No comparte la opinión del representante de Suiza de que aún no ha llegado el momento de emprender una actividad normativa. Por otra parte, apoya la propuesta de actualizar las Notas de la CNUDMI sobre la Organización del Proceso Arbitral.

29. Si bien la arbitrabilidad es una cuestión importante, su delegación considera que la Comisión no está en condiciones de ejercer una gran influencia en esa esfera, debido a las diferencias que existen las políticas públicas.

30. **El Presidente** recuerda a la Comisión que en la sesión anterior convino en que el primer tema que debería examinarse después de concluir la elaboración de una convención sobre la transparencia es la actualización de las Notas sobre la Organización del Proceso Arbitral.

31. **El Sr. Apter** (Israel) dice que, si bien la cuestión de los procedimientos paralelos suscita un gran interés, su delegación considera que es pertinente únicamente para un número relativamente reducido de Estados. Los criterios para la elección de temas deben basarse en su pertinencia para los Estados y el sector del arbitraje y, como señaló el representante de la República Checa, en la probabilidad de que la labor de la Comisión tenga efectos prácticos.

32. **El Presidente** señala que los procedimientos paralelos pueden referirse a casi todos los aspectos del arbitraje. Por ejemplo, la cuestión de los procedimientos paralelos se plantea en el ámbito del arbitraje relacionado con las inversiones. Otra cuestión es la aplicación del principio de litispendencia a los tribunales arbitrales, que puede plantearse en los arbitrajes comerciales. Una tercera cuestión es la referida a la existencia paralela de actuaciones judiciales y procesos arbitrales, así como la interpretación del artículo 8 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional. Por ejemplo, la aplicación errónea del criterio para suspender las actuaciones judiciales a favor de un proceso arbitral ha causado muchos problemas en el mundo en desarrollo.

33. **El Sr. Popkov** (Belarús) manifiesta que el Grupo de Trabajo II debería seguir ocupándose de las cuestiones relativas a la solución de controversias comerciales con

miras a promover el desarrollo de buenas prácticas en esa esfera.

34. Dado que los Estados agradecerán sobremanera toda orientación en lo que respecta a los procedimientos paralelos en el marco del arbitraje en materia de inversiones, el orador se pregunta si la secretaría podría examinar la posibilidad de elaborar directrices sobre el tema en colaboración con otros foros.

35. La **Sra. Wilhelmsen** (Dinamarca) señala que se debe establecer un marco claro para las tareas asignadas al Grupo de Trabajo II. Su delegación considera que se debe asignar prioridad a la labor relativa a los procedimientos paralelos y al principio de la litispendencia. El Grupo de Trabajo podría por ejemplo, examinar, cuál es la ley aplicable a la validez de los acuerdos de arbitraje, puesto que aún no existe ninguna norma uniforme aplicable a la etapa anterior al laudo. Esta cuestión, debería tal vez abordarse tomando en cuenta lo establecido en los artículos II y III de la Convención de Nueva York.

Se suspende la sesión a las 15.30 horas y se reanuda a las 16.15 horas.

Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación

a) Finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado (continuación) (A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.3 y Add.4)

36. **El Presidente** invita a que se formulen observaciones sobre la parte del proyecto de informe que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.3.

37. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) dice que la última oración del párrafo 2, en la que se hace referencia al párrafo 40 del documento A/CN.9/760, induce a error, ya que da a entender que la Comisión hace suyo el contenido de ese párrafo. El orador propone que se suprima la oración y que se modifique la penúltima oración para que diga: “La Comisión recordó el párrafo 40 del documento A/CN.9/760, pero estuvo de acuerdo en que cuando en el reglamento se invitaba a un tribunal a que ejerciera sus facultades discrecionales, se aplicaban claramente, de hecho, los criterios enumerados en el artículo 1, párrafo 4)”. Se podrían añadir las siguientes palabras al final de esa oración si se obtiene el respaldo necesario: “independientemente de que en el reglamento se utilizaran las palabras facultades discrecionales”.

38. **El Presidente** propone modificar las palabras iniciales de la siguiente manera: “La Comisión examinó el párrafo 40”.

39. *Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.*

40. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) propone que se sustituyan las palabras “Dos delegaciones” en la segunda oración del párrafo 7, por “Varias delegaciones”.

41. *Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.*

42. La **Sra. Pólit** (Ecuador) propone que después de las palabras “(el Convenio del CIADI)”, que figuran en el párrafo 18, se añada la frase “y por otras delegaciones, como las del Ecuador, la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia, que han denunciado el CIADI”.

43. **El Presidente** señala que no es práctica de la Comisión hacer constar los nombres de los Estados en el informe. Por lo tanto, propone insertar en su lugar la siguiente frase: “y que otros países han denunciado el Convenio del CIADI”. La oración continuaría de la siguiente manera: “y que, por consiguiente, esos países se sentirían más cómodos apoyando la opción del nombramiento temporal de la Corte Permanente de Arbitraje”.

44. *Queda aprobado el párrafo 18 en su forma enmendada.*

45. El **Sr. Popkov** (Belarús) propone modificar la segunda oración del párrafo 21 para que diga: “También se dijo que la Corte Permanente de Arbitraje administraba una variedad de casos que involucraban a Estados, incluidas controversias entre Estados de conformidad con tratados y controversias relacionadas con contratos celebrados entre Estados y particulares, lo que para algunas delegaciones la convertía en la candidata idónea”.

46. El **Sr. Daly** (Corte Permanente de Arbitraje) propone que se modifique la primera oración del párrafo 21 de la siguiente manera: “Otras delegaciones consideraban que la función del Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje como encargado de designar a la autoridad nominadora conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI establecía un vínculo más natural con la CNUDMI”. Además, propone modificar el texto entre corchetes que figura en la última oración del párrafo para que diga: “publicación gratuita de hasta 50 documentos y una tasa fija de 750 euros por la publicación de más de 50 documentos”.

47. *Queda aprobado el párrafo 21 en su forma enmendada.*

48. El **Sr. Kordač** (República Checa) propone que la frase “acordó por consenso que la Corte Permanente de Arbitraje debía ser la institución designada para desempeñar la función de archivo” se redacte de forma más positiva.

49. El **Sr. Spelliscy** (Canadá) propone el siguiente texto: “acordó por consenso que se designase a la Corte Permanente de Arbitraje para desempeñar la función de archivo”.

50. *Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.*

51. El **Sr. Schneider** (Suiza) propone que se añada la siguiente frase al final del párrafo 23: “y que, si para esa fecha la Comisión aún no hubiese creado el archivo, se reconsiderase la decisión”.

52. El **Presidente** dice que la adición propuesta parece dar a entender que podría ser necesario repetir el difícil proceso de designar una institución para que desempeñe la función de archivo.

53. La **Sra. Pólit** (Ecuador) se opone a la propuesta del representante de Suiza.

54. La **Sra. Le Duc Hanh** (Observadora de Viet Nam), con el apoyo de la **Sra. Escobar** (Ecuador), hace notar que algunas delegaciones expresaron su preocupación por que la solución temporal pudiera pasar a ser permanente. Fue por ello que se decidió disponer que se volviera a examinar la situación.

55. El **Presidente** propone que se modifique el párrafo 23 para que diga: “Se expresó preocupación por la posibilidad de que la solución temporal de que la Corte Permanente de Arbitraje desempeñase las funciones de archivo adquiriera carácter permanente y, por consiguiente, la Comisión solicitó que, en su próximo período de sesiones, en 2014, la Secretaría informase sobre el estado del establecimiento y funcionamiento del archivo para la transparencia”.

56. *Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmendada.*

57. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) dice que su delegación desea introducir el siguiente nuevo párrafo después del párrafo 24: “Se expresó la opinión de que el mandato del Grupo de Trabajo consistía en estudiar opciones para hacer que el reglamento sobre la transparencia fuera aplicable a los tratados de inversión

existentes, pero que no determinaba el resultado a favor de una recomendación”.

58. *Se convino en insertar el nuevo párrafo después del párrafo 24.*

59. El **Sr. Lebedev** (Federación de Rusia) dice que debería aclararse o suprimirse la última frase del párrafo 26, “una recomendación destinada a promover el empleo del reglamento no era el medio adecuado para restringir el uso de este”.

60. El **Presidente** sugiere sustituir toda la segunda oración por la siguiente: “Esa solicitud no obtuvo apoyo”.

61. *Queda aprobado el párrafo 26 en su forma enmendada.*

62. El **Sr. Lee Jae Min** (República de Corea) propone que se sustituyan las palabras “ese tratado”, que figura al final del párrafo 28, por “esa convención”.

63. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) propone que se sustituyan las palabras “Se respaldó”, que figuran al principio del párrafo 28, por “Varias delegaciones respaldaron”. Además, propone que se modifique la última oración para que diga: “Se subrayó que no se crearía ninguna expectativa ni se emitiría juicio de valor alguno respecto de aquellos Estados que decidiesen no firmar o ratificar esa convención”.

64. El **Presidente** dice que en el párrafo 34 ya se hace referencia a que no habrá ningún juicio de valor.

65. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) señala que, en ese caso, las palabras “ningún otro Estado tendría la obligación de firmar o ratificar”, que figuran en la versión original de la oración, deberían sustituirse por las palabras “no se crearía la expectativa de que ningún otro Estado firmase o ratificase”.

66. *Queda aprobado el párrafo 28 en su forma enmendada.*

67. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América), observando que si bien en los párrafos 28 a 31 se recogen expresiones de apoyo a la preparación de una convención, en el párrafo 32 se hacen constar ciertas reservas, por lo que propone que el párrafo comience con las palabras “En respuesta a ello, se observó que” en lugar de “Además, se reconoció que”.

68. *Queda aprobado el párrafo 32 en su forma enmendada.*

69. El **Sr. Loh Kong Yue** (Singapur) propone que se inserte un nuevo párrafo después del párrafo 32, que diga

lo siguiente: “Se expresó la opinión de que, si bien las delegaciones habían reconocido la importancia de la transparencia, también debía reconocerse que la solución de transacción prevista en el reglamento no era perfecta y una convención tendría el efecto de perturbar el delicado equilibrio alcanzado en el artículo 1 del reglamento”.

70. **El Presidente** sugiere que se supriman las palabras “también debía reconocerse que”, puesto que podrían interpretarse como reflejo de un acuerdo. Por consiguiente, la oración quedaría redactada como sigue: “Se expresó la opinión de que, si bien las delegaciones habían reconocido la importancia de la transparencia, la solución de transacción prevista en el reglamento no era perfecta y una convención tendría el efecto de perturbar el delicado equilibrio alcanzado en el artículo 1 del reglamento”. Habida cuenta de que en el párrafo 29 se aborda la solución de transacción, **el Presidente** propone que la nueva oración se inserte en ese párrafo y no después del párrafo 32.

71. *Así queda acordado.*

72. **El Presidente** dice que debería suprimirse el párrafo 35, ya que su contenido se sustituirá por los tres primeros párrafos de la sección del proyecto de informe que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.4, que a continuación leerá en voz alta un representante de la secretaría.

73. Entre tanto, **el Presidente** propone que se inserte un nuevo párrafo 35, que diga: “Para que constara oficialmente, se señaló que el proyecto de texto de una convención, presentado a la Comisión en el párrafo 5 del documento A/CN.9/784, era una propuesta de la secretaría que el Grupo de Trabajo aún no había examinado”.

74. *Así queda acordado.*

75. La **Sra. Salasky** (Secretaría) lee en voz alta los tres primeros párrafos del documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.4.

76. **El Presidente** dice que entiende que esos párrafos son aceptables para la Comisión.

77. *Así queda acordado.*

78. *Queda aprobado en su totalidad, en su forma enmendada, el proyecto de informe sobre la finalización y aprobación del reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado.*

Labor futura en materia de solución de controversias comerciales (*continuación*) (A/CN.9/785)

79. **El Presidente** sugiere que la Comisión pida a la secretaría que, si los recursos lo permiten, siga estudiando la cuestión de los procedimientos paralelos e informe a la Comisión en 2014 sobre la manera en que podrá abordarse la cuestión.

80. En respuesta a una pregunta formulada por el **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América), **el Presidente** confirma que no se adoptará ninguna decisión sobre la cuestión hasta la última semana del período de sesiones en curso.

Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y la conciliación

c) Preparación de una guía sobre la Convención de Nueva York de 1958 (*continuación*) (A/CN.9/786)

81. **El Presidente** dice que la Comisión tal vez desee aplazar la adopción de una decisión sobre el rango que tendrá la guía sobre la Convención de Nueva York de 1958 hasta el siguiente período de sesiones de la Comisión, cuando se disponga del texto completo de la guía para su examen. A fin de disipar las preocupaciones existentes, en toda versión de la guía que se publique en el interín se debería hacer constar la salvedad de que la CNUDMI aún no ha decidido qué rango tendría la guía. En el período de sesiones de 2014, la secretaría presentará una recomendación a la Comisión sobre el rango de la guía y la forma en que debería publicarse.

82. El **Sr. Caplan** (Estados Unidos de América) dice que debería abordarse la cuestión de si la guía será publicada o no por las Naciones Unidas.

83. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) señala que los capítulos que se finalicen antes del siguiente período de sesiones se publicarán como notas de la secretaría para que los miembros de la Comisión puedan examinarlos. Toda reserva que expresen los miembros se hará constar fielmente en los documentos y en el sitio web.

84. El **Sr. Apter** (Israel) dice que el examen a fondo del contenido de los capítulos restantes puede llevar algún tiempo. La Comisión podría tal vez considerar la posibilidad de divulgar una versión abreviada de la guía a fin de asegurar que todos los Estados tengan la oportunidad de analizarla debidamente.

85. **El Presidente** dice que la secretaría tendrá en cuenta todas las inquietudes expresadas. De no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea aplazar la adopción de una decisión sobre la Convención de Nueva York hasta el siguiente período de sesiones.

86. *Así queda acordado.*

Se levanta la sesión a las 17.05 horas.

**Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación
de un registro de garantías reales**

**Acta resumida de la 966ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
Viena, el viernes 12 de julio de 2013, a las 9.30 horas**

[A/CN.9/SR.966]

Presidente: Sr. Schöll (Suiza)

Más tarde: Sr. Labardini Flores (Vicepresidente) (México)

Se declara abierta la sesión a las 9.45 horas.

**Examen de cuestiones relacionadas con el arbitraje y
la conciliación**

**d) Concursos de arbitraje comercial internacional
simulado (A/CN.9/786)**

1. El **Presidente** invita a la Secretaría a presentar el tema 4 d) del programa.

2. La **Sra. Salasky** (Secretaría) dice que la Asociación para la Promoción y Organización del Concurso de Arbitraje Comercial Internacional Simulado Willem C. Vis celebró el 20º concurso simulado en Viena del 22 al 28 de marzo de 2013. Como en años anteriores, el concurso fue patrocinado por la Comisión y contó con la participación de 291 equipos de facultades de derecho de 66 países. La fase de presentación de argumentos orales para el 21º Concurso de Arbitraje Comercial Internacional Simulado Willem C. Vis se celebrará en Viena del 11 al 17 de abril de 2014.

3. La Comisión también copatrocinó el Décimo Concurso de Arbitraje Comercial Internacional Simulado Willem C. Vis (Oriente), celebrado del 11 al 17 de marzo de 2013. El equipo ganador fue el de la Universidad de Canberra.

4. La **Sra. Montineri** (Secretaría) dice que los concursos simulados brindan a estudiantes de todo el mundo excelentes oportunidades de adquirir experiencia en la esfera del arbitraje. La Comisión copatrocinó el Quinto Concurso de Arbitraje Comercial Internacional Simulado, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid del 15 al 20 de abril de 2013. El Sexto Concurso en Madrid se celebrará del 21 al 25 de abril de 2014.

5. El **Sr. Lebedev** (Federación de Rusia) destaca el valor de los concursos simulados copatrocinados por la CNUDMI como un medio de promover las actividades destinadas a atraer a la comunidad de estudiantes de distintas partes del mundo y crear conciencia entre los

jóvenes juristas con respecto a la labor de la Comisión. Por su parte, al seguir la evolución académica de algunos estudiantes rusos que participaron en esos concursos ha observado que sus disertaciones suelen centrarse en cuestiones que guardan relación con la labor de la CNUDMI. Propone que se invite a los ganadores de los concursos simulados a asistir a los períodos de sesiones de la Comisión.

6. El **Sr. Adensamer** (Austria) expresa su apoyo a la propuesta de invitar a los ganadores a asistir a algunas de las reuniones celebradas durante los períodos de sesiones de la Comisión. A esos efectos, deberían seleccionarse reuniones en las que se examinen cuestiones particularmente importantes.

7. El **Presidente** entiende que la Comisión desea poner de relieve en su informe la importante función que cumplen los concursos simulados para familiarizar a los estudiantes con la labor de la CNUDMI. Invita a la secretaria a formular observaciones sobre la propuesta de invitar a los ganadores a asistir a sesiones de la Comisión.

8. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que aunque la secretaria no puede dedicar un gran volumen de recursos al copatrocinio por la CNUDMI de los concursos simulados, está tratando de entablar vínculos más estrechos con los equipos organizadores de los concursos en Viena y en otros lugares. En consecuencia, estudiará la posibilidad de llevar a la práctica la propuesta formulada por los representantes de la Federación de Rusia y Austria.

Elección de la Mesa (continuación)

9. El **Sr. Cabrera** (México), hablando en nombre de los Estados de América Latina y el Caribe, propone que se elija al Sr. Labardini Flores (México) Vicepresidente de la Comisión.

10. La **Sra. Escobar** (El Salvador), el **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) y el **Sr. Castellano** (Italia) apoyan la propuesta.

11. *El Sr. Labardini Flores (México) es elegido Vicepresidente de la Comisión por aclamación.*

12. **El Presidente** invita al Sr. Labardini Flores a presidir el debate sobre el tema 5 del programa.

13. *El Sr. Labardini Flores (México) ocupa la Presidencia.*

Examen de cuestiones relacionadas con las garantías reales

a) **Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación de un registro de garantías reales** (A/CN.9/WG.VI/WP.54 y Add.1 a 4; A/CN.9/781 y Add.1 y 2; A/CN.9/764 y 767; A/CN.9/XLVI/CRP.4)

14. **El Presidente** invita a la secretaría a presentar los documentos relacionados con el tema 5 a) del programa.

15. **El Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que el proyecto de Guía legislativa técnica para la creación de un registro de garantías reales (el proyecto de guía sobre el registro) figura en varios documentos preparados por el Grupo de Trabajo VI (Garantías reales), así como en varios documentos de la Comisión. Dado que el Grupo de Trabajo aprobó el proyecto de guía sobre el registro en abril de 2013, no ha sido posible elaborar una versión revisada completa a tiempo para presentarla a la Comisión en el actual período de sesiones. Por tanto, los documentos del Grupo de Trabajo que la Comisión tiene ante sí (A/CN.9/WG.VI/WP.54 y Add.1 a 4) contienen el comentario relativo al proyecto de guía sobre el registro. En el documento A/CN.9/781 de la Comisión se incluye un resumen de todas las modificaciones a la Guía aprobadas por el Grupo de Trabajo. La adición 1 del documento A/CN.9/781 contiene las recomendaciones relativas al proyecto de guía sobre el registro y en la adición 2 figuran ejemplos de los formularios de registro. Los informes del Grupo de Trabajo VI están contenidos en los documentos A/CN.9/764 y 767. Por último, en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.4 figura un proyecto de decisión relativo a la aprobación de la Guía.

16. **El Presidente** invita a los miembros de la Comisión a hacer observaciones sobre el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54, que contiene el proyecto de prefacio e introducción del proyecto de guía sobre el registro.

17. *Queda aprobado el prefacio.*

18. **El Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) dice que la Organización

de Aviación Civil Internacional aprobó recientemente una quinta edición de las Normas y procedimientos para el registro internacional. Por consiguiente, propone que en el párrafo 4 g) se actualice la referencia a las Normas y procedimientos.

19. *Así queda acordado.*

20. **El Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que conviene leer los párrafos 8 a 16 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54, relativos a la terminología y la interpretación, a la luz de los párrafos 3 a 9 del documento A/CN.9/781, en los que se señalan los cambios aprobados por el Grupo de Trabajo. La terminología figura en el documento A/CN.9/781/Add.1, que contiene asimismo dos notas dirigidas a la Comisión sobre cuestiones surgidas posteriormente a la aprobación del texto por el Grupo de Trabajo. Esas cuestiones guardan relación con los términos “enmienda” y “autor de la inscripción”. El orador asegura a la Comisión que la secretaría hará los cambios de redacción que sean necesarios para mantener la coherencia terminológica.

21. **El Sr. Henning** (Estados Unidos de América), refiriéndose a la definición del término “otorgante” como “la persona identificada en la notificación como el otorgante” en el párrafo 11 del documento de trabajo y en el párrafo e) del documento A/CN.9/781/Add.1, propone que se añadan las palabras “en el espacio previsto” después de la palabra “identificada”. Propone que en ambos documentos se modifique de manera análoga la definición de “acreedor garantizado”, que actualmente dice lo siguiente: “Por ‘acreedor garantizado’ se entenderá la persona identificada en la notificación como el acreedor garantizado”.

22. *Así queda acordado.*

23. **El Sr. Henning** (Estados Unidos de América) pide que se aclare cómo funcionaría la nueva definición de “otorgante”, es decir, la persona que presenta el formulario previsto para la notificación de inscripción al registro, en un contexto de inscripción en soporte de papel, cuando resulta evidente que la persona que entrega el formulario de la notificación al registro es un mensajero u otro tipo de proveedor de servicios de mensajería y no el autor de la inscripción. Tal vez puede indicarse que el término no se aplica a un agente encargado de la entrega.

24. **El Presidente** propone que en el comentario se explique que el mensajero u otro tipo de proveedor de servicios de mensajería utilizado por el autor de la inscripción para entregar una notificación en soporte de papel no se considerará autor de la inscripción.

25. *Así queda acordado.*

26. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) propone que se simplifique la definición del término “dirección” combinando las opciones i) y ii) relativas a una dirección física, es decir una calle o un número de casilla de correos.

27. *Así queda acordado.*

28. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) propone que se suprima la opción iv), “una dirección que sirva para comunicar información”, puesto que es algo confusa y el comentario no es explícito en cuanto a lo que designa.

29. El **Sr. Castellano** (Italia) propone que en el comentario se explique la referencia a una dirección que sirva para comunicar información.

30. La **Sra. Walsh** (Canadá) apoya la propuesta del representante de Italia. El mejor enfoque será el que brinde flexibilidad. Estima que la opción iv) puede suprimirse si la secretaría explica en el comentario que el Estado promulgante puede permitir que los autores de una inscripción tengan la posibilidad de elegir entre diversos tipos de direcciones.

31. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) dice que en el comentario pueden incluirse ejemplos de otros tipos de direcciones que pueden ser eficaces para comunicar información. El formulario de inscripción debería diseñarse de modo que permita a los autores de una inscripción elegir un determinado tipo de dirección.

32. El **Presidente** entiende que la Comisión desea suprimir la opción iv) e incluir en el comentario la explicación propuesta para los Estados promulgantes.

33. *Así queda acordado.*

34. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano), refiriéndose a la definición de “reglamento”, propone que se sustituyan las palabras “el conjunto de reglas que aplique el Estado promulgante” por “el conjunto de reglas que adopte el Estado promulgante”.

35. *Así queda acordado.*

36. El **Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre las demás secciones del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54, empezando por el párrafo 17.

37. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) propone que en el párrafo 23 c) se supriman las palabras “ha de indicar la intención del otorgante de crear una garantía real” puesto

que ese aspecto del acuerdo queda abarcado en el párrafo 23 b).

38. *Así queda acordado.*

39. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) observa que la segunda oración del párrafo 28 dice que la inscripción de una notificación es el único método para lograr la oponibilidad a terceros para todos los tipos de bienes gravados. Señala a la atención de la Comisión la recomendación 50 de la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*, según la cual solo cabe hacer oponible una garantía real sobre un derecho a percibir el producto de una promesa independiente confiriendo al acreedor garantizado el control del derecho a recibir el producto de dicha promesa independiente. El orador propone que se modifique la segunda oración a fin de hacer referencia a esa recomendación e indicar que la inscripción de una notificación es el método de lograr la oponibilidad a terceros para todos los tipos de bienes gravados “excepto con respecto a una garantía real sobre un derecho a recibir el producto de una promesa independiente”.

40. *Así queda acordado.*

41. *Queda aprobada la sección de la introducción del proyecto de guía sobre el registro contenida en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54 en su forma enmendada.*

42. El **Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre la parte restante del proyecto de introducción contenido en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1.

43. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) dice que el debate al que se hace referencia en el párrafo 18 con respecto a la coordinación con los registros especiales de bienes muebles es importante, pero solo si las garantías reales sobre determinados bienes como material rodante ferroviario u objetos aeronáuticos quedan abarcadas por el derecho de las operaciones garantizadas. Si este excluye esos bienes y existe un registro especial para las respectivas garantías reales, no se requiere coordinación.

44. El **Presidente** entiende que la Comisión está de acuerdo en modificar la sección a fin de aclarar ese aspecto.

45. *Así queda acordado.*

46. *Queda aprobada la parte restante de la introducción al proyecto de guía sobre el registro en su forma enmendada.*

47. El **Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre el capítulo I de la Guía sobre un

registro, relativo a la creación y funciones del registro de garantías reales, que figura en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, y sobre las recomendaciones 1 a 3 contenidas en el documento A/CN.9/781/Add.1.

48. *Quedan aprobados el capítulo I y las recomendaciones 1 a 3.*

49. **El Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre el capítulo II, relativo al acceso a los servicios del registro, que figura en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.1, y sobre las recomendaciones 4 a 10 contenidas en el documento A/CN.9/781/Add.1.

50. El **Sr. Henning** (Estados Unidos de América) propone que en la recomendación 6, párrafo a) i), se inserte la palabra “aplicable” antes de la palabra “formulario” dado que el registro requerirá varios tipos distintos de formularios para fines diferentes.

51. *Así queda acordado.*

52. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) señala a la atención de la Comisión la nota adjunta a la recomendación 7, apartado c). Invita a la Comisión a considerar la posibilidad de añadir las siguientes palabras al principio del apartado: “A reserva de lo dispuesto en las recomendaciones 8, apartado a), y 10, apartado a).” La adición propuesta tiene por objeto explicar que el registro realiza un examen a fondo, de conformidad con las recomendaciones 8 y 10, únicamente para asegurar que se inscriba algún tipo de información legible en una notificación. Otra posibilidad es explicar esta cuestión en el comentario.

53. La **Sra. Walsh** (Canadá) apoya la modificación propuesta por la secretaría.

54. *Queda aprobada la recomendación 7 en su forma enmendada.*

55. El **Sr. Henning** (Estados Unidos de América) propone que se modifique la recomendación 8, apartado a) para que diga lo siguiente: “El registro rechaza la inscripción de una notificación si no se incorporó información en cada uno de los espacios previstos de obligada cumplimentación o si la información incorporada es ilegible.”

56. *Así queda acordado.*

57. *Quedan aprobados el capítulo II y las recomendaciones 4 a 10 en su forma enmendada.*

Se suspende la sesión a las 11.10 horas y se reanuda a las 11.45 horas.

58. **El Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre el capítulo III, relativo a la inscripción registral, que figura en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, y sobre las recomendaciones 11 a 22 contenidas en el documento A/CN.9/781/Add.1.

59. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano), refiriéndose al párrafo 44 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, dice que el autor de la inscripción puede presentar una notificación con un anexo. Propone que se aclare que en ese caso el anexo pasa a ser parte de la notificación y deberá ser retirado del registro accesible al público junto con la notificación cuando la validez de esta haya expirado.

60. *Así queda acordado.*

61. El **Sr. Henning** (Estados Unidos de América) dice que la recomendación 11 a) se parece mucho a la recomendación 70 de la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*. No es una instrucción dirigida al registro o al autor de la inscripción sino una simple descripción del efecto jurídico de ciertos acontecimientos. El Grupo de Trabajo VI ha decidido con razón que se incluya en el proyecto de guía sobre el registro para que el secretario y los usuarios del registro comprendan el efecto jurídico resultante. Sin embargo, podría ser útil que en el comentario se ponga de relieve el parecido con la recomendación 70 para que el Estado promulgante adopte una redacción análoga en su régimen legal de las operaciones garantizadas y en su guía sobre el registro.

62. El **Sr. Boettcher** (Alemania) y el **Sr. Dache** (Kenya) apoyan la propuesta del representante de los Estados Unidos.

63. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) señala a la atención de la Comisión el párrafo 32 del documento A/CN.9/781, relativo a las enmiendas al proyecto de guía sobre el registro aprobadas por el Grupo de Trabajo, el cual es aplicable a la acotación hecha por los representantes de los Estados Unidos, Alemania y Kenya. El párrafo dice, entre otras cosas, que cuando sea necesario, puede añadirse texto del siguiente tenor: “Generalmente, esa norma se incluiría en el régimen legal de las operaciones garantizadas del Estado promulgante. No obstante, el Estado promulgante podrá decidir, en función de su método legislativo y convenciones de redacción concretas, incluirla o reiterarla en el reglamento”.

64. La **Sra. Walsh** (Canadá) dice que la secretaria debería insertar esa salvedad en varias partes del proyecto.

65. *Así queda acordado.*

66. El **Presidente** toma nota de que se ha pedido a la Comisión que considere si la recomendación 12, relativa a la asignación de un número de inscripción, debería colocarse más cerca de la recomendación 16, relativa a la indexación de la información, o formar parte de dicha recomendación, puesto que la asignación de un número de inscripción por el registro tiene que ver con la indexación de información en el fichero del registro.

67. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) señala a la atención de la Comisión que si la recomendación 12 se incorpora en la recomendación 16, se omitiría el encabezamiento “Número de inscripción”.

68. La **Sra. Walsh** (Canadá) y el **Sr. Castellano** (Italia) apoyan la propuesta de colocar la recomendación 12 más cerca de la recomendación 16.

69. El **Sr. Weise** (American Bar Association) dice que para los autores de una búsqueda la recomendación 12 puede parecer pertinente únicamente si se incorpora a la recomendación 16, mientras que la pertinencia del número de inscripción, en caso de enmienda, se refleja claramente en la recomendación 30.

70. La **Sra. Walsh** (Canadá) propone que se cambie el título de la recomendación 16 a “Número de inscripción e indexación u otras formas de organizar la información en el fichero del registro”. La recomendación 16 no es solo una instrucción dirigida a los autores de una búsqueda; es una instrucción al registro.

71. El **Presidente** propone que se inserten las palabras “A los efectos de las recomendaciones 16, 18, 30, 32 y 34,” al principio de la recomendación 12, manteniéndola por separado como recomendación 15 y colocándola inmediatamente antes de la recomendación 16. La secretaria puede encargarse de la redacción final.

72. *Así queda acordado.*

73. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano), refiriéndose a la recomendación 13, propone que se armonice el texto del apartado c) de la variante A con el de los apartados correspondientes de la variante B y la variante C. El texto resultante sería: “En caso de prórroga, el nuevo plazo podría comenzar cuando expire el plazo en curso”.

74. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) señala a la atención de la Comisión la nota que figura a continuación de la recomendación 13, en la que se plantea una cuestión que

podría hacer necesarias algunas modificaciones a la variante C. Actualmente, el límite máximo conforme a la variante C parece aplicarse a cada notificación de enmienda. En consecuencia, si el nuevo plazo comienza cuando expira el plazo en curso, cuando hay más de una enmienda que prorroga el plazo de vigencia, en realidad no hay diferencia entre las variantes B y C. A fin de lograr el objetivo de la variante C de fijar un plazo máximo, el nuevo plazo podría comenzar: a) cuando se inscriba la notificación de enmienda con el plazo máximo que le sea aplicable; o b) cuando expire el plazo en curso, siempre que todas las notificaciones juntas no excedan del plazo máximo.

75. El **Presidente** propone el siguiente texto para el apartado c) de la variante C: “En caso de prórroga, el nuevo plazo se inicie: a) cuando se inscriba la notificación de enmienda con el plazo máximo que le sea aplicable; o b) cuando expire el plazo en curso, siempre que todas las notificaciones juntas no excedan del plazo máximo”.

76. El **Sr. Dache** (Kenya) expresa su apoyo a esa propuesta.

77. La **Sra. Walsh** (Canadá) entiende que el texto propuesto consta de dos alternativas y no de dos enfoques simultáneos. La Comisión tal vez necesite decidir cuál de las dos alternativas es la más apropiada.

78. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que en el caso del apartado a), cada notificación de enmienda no excederá del plazo máximo, mientras que según el apartado b), todas las notificaciones de enmienda juntas no deberán exceder del plazo máximo.

79. La **Sra. Walsh** (Canadá) señala que el enfoque adoptado con respecto al apartado a) no contribuirá realmente a aplicar la política reflejada en la variante C, apartado c). Por esta razón, su delegación es partidaria del enfoque adoptado en el apartado b).

80. El **Sr. Weise** (American Bar Association) dice que algunas operaciones son de muy larga duración. Si el efecto acumulativo de todas las enmiendas depende de un plazo absoluto, ese plazo debiera imponerse a las operaciones que puedan ser prorrogables por motivos comerciales válidos sin que ello suponga un uso indebido del sistema de registro. Por tanto, el objetivo de la variante C es que toda notificación esté sujeta a un determinado plazo, pero no que exista un plazo acumulativo, pues en este último caso la variante C será aún más restrictiva que la variante A.

81. El **Sr. Castellano** (Italia) concuerda con la observación formulada por la representante del Canadá sobre el enfoque relativo al apartado a), así como con la

acotación hecha por el representante de la American Bar Association en el sentido de que no es deseable imponer un plazo máximo en ciertas circunstancias. La intención de la variante C, desde el punto de vista de la política, es distinta a la que sirve de base a la variante B. Si se inscriben simultáneamente múltiples notificaciones de enmienda, cada una por un período de 20 años, se producirá una laguna. El orador sugiere que se especifique en el texto que la inscripción de múltiples enmiendas por prórrogas de 20 años no es aceptable.

82. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que se han considerado tres posibilidades. La primera opción, conforme al apartado a), permitiría inscribir un número

ilimitado de notificaciones de enmienda por un plazo de 20 años, resultado que no es coherente con el propósito de la variante C. Una segunda opción consiste en permitir una sola enmienda por un plazo de 20 años, lo que significa que la notificación inicial de prórroga por 20 años puede ser objeto de una sola enmienda adicional por 20 años. La opción prevista en el apartado b) consiste en que todas las notificaciones de enmienda juntas inscritas una vez expirado el plazo no excedan de 20 años.

83. **El Presidente** dice que la Comisión continuará sus deliberaciones sobre el tema en la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

**Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación
de un registro de garantías reales (continuación)**

**Acta resumida de la 967ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
el viernes 12 de julio de 2013, a las 14.00 horas**

[A/CN.9/SR.967]

Presidente: Sr. Labardini Flores (Vicepresidente) (México)

Se declara abierta la sesión a las 14.15 horas.

Examen de cuestiones relacionadas con las garantías reales

a) Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación de un registro de garantías reales (A/CN.9/WG.VI/WP.54 y Add.1 a 4, A/CN.9/781 y Add.1 y 2; A/CN.9/764 y 767; A/CN.9/XLVI/CRP.4) (continuación)

1. El **Presidente** invita a la Comisión a reanudar el examen del capítulo III, relativo a la inscripción registral (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2), del proyecto de Guía Legislativa Técnica sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales (proyecto de guía sobre el registro), y de las recomendaciones 13 a 22 (A/CN.9/781/Add.1).

2. Se han formulado varias observaciones y propuestas con respecto a la recomendación 13, relativa al plazo de vigencia de la inscripción de una notificación.

3. La **Sra. Walsh** (Canadá) dice que la redacción de la variante C debería ajustarse a fin de garantizar que la inscripción de una notificación inicial sea válida por el período indicado por el autor de la inscripción pero no exceda de un determinado período máximo en un momento dado. Por lo tanto, el apartado c) de la variante C debería disponer que, en caso de prórroga, la inscripción de una enmienda que especifique un nuevo período sujeto al límite máximo surtirá efecto tan pronto como dicha enmienda se inscriba.

4. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que se está haciendo referencia a dos cuestiones simultáneamente. Una de ellas se refiere a la redacción más adecuada de las variantes A, B y C. La segunda tiene que ver con el fondo de la variante C. Algunas delegaciones celebraron consultas desde la sesión anterior y produjeron lo que podría constituir la redacción convenida de la variante A. Sin embargo, todavía hay algunas hipótesis diferentes respecto del propósito de la variante C. Por ejemplo, en la variante A el período, que podría ser de cinco años, lo fija el Estado. Si se aplicara la

redacción actual de la variante A, podría añadirse un segundo período de cinco años en cualquier momento durante los primeros cinco años. En consecuencia, si se añadiera un segundo período de cinco años en el segundo año, el período total se ampliaría a 10 años. Ahora bien, esa medida solamente podría adoptarse una vez. Su delegación supuso que la variante C surtiría un efecto similar, pero que la parte decidiría el correspondiente período de vigencia, así como el período de prórroga, siempre que no excediera del límite máximo. Por lo tanto, si el plazo legal máximo fuera de 20 años, un acreedor garantizado podría inscribir una notificación en el registro por un período de 20 años y establecer una prórroga de 20 años en cualquier momento durante ese período. Durante las consultas se propuso establecer que dicho plazo solamente pudiera prorrogarse una vez, lo que resolvería el problema de la coincidencia con la variante B. Como otras delegaciones interpretan la opción C de un modo algo diferente, antes que nada la Comisión debería aclarar si la intención es que las partes puedan prorrogar el plazo hasta el máximo previsto en la variante C del mismo modo que en la variante A o si el período máximo que podría fijarse en un momento dado no debería exceder del plazo establecido.

5. El **Sr. Weise** (American Bar Association) dice que la opción C se concibió para evitar posibles abusos excluyendo la posibilidad de múltiples prórrogas durante un período determinado y no para establecer un total máximo de todos los períodos.

6. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que en la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas (Guía sobre las Operaciones Garantizadas)* solamente se contemplan las variantes A y B. La variante C es resultado de las deliberaciones del Grupo de Trabajo VI. Varias delegaciones han opinado que una notificación o una enmienda no debería ser válida por tiempo indefinido y que el registro debería vaciarse en algún momento. Ese es el propósito del límite máximo. Sin embargo, hay dos posibilidades. El límite podría ser el período total, por ejemplo 20 años, independientemente del número de

enmiendas introducidas, o podría aplicarse un límite máximo a cada notificación de enmienda. Si la Comisión considera que el límite máximo debería aplicarse a cada notificación de enmienda, sería aplicable el texto que figura en la nota a la recomendación 13: “el nuevo plazo podría comenzar cuando se inscriba la notificación de enmienda con el plazo máximo que le sea aplicable”. Si la Comisión no pudiera apoyar esa solución, podría ser útil pedir a un grupo de miembros que presentara una propuesta diferente.

7. **El Presidente** invita a un grupo de miembros interesados a que se reúna oficiosamente y presente una propuesta a la Comisión.

8. Invita asimismo a que se formulen observaciones sobre las recomendaciones 14 a 22.

9. **El Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) propone modificar la recomendación 14 para que diga: “El reglamento debería disponer que una notificación pueda inscribirse antes o después de que se constituya una garantía real o se celebre un acuerdo de garantía”. La palabra “la” que figuraba antes de “garantía real” se cambió por la palabra “una”, y la palabra “el” que figuraba antes de “acuerdo de garantía” se cambió por la palabra “un”, porque una sola notificación podría ser suficiente respecto de muchas garantías reales y acuerdos.

10. *Queda aprobada la recomendación 14, en su forma enmendada.*

11. *Quedan aprobadas las recomendaciones 15 a 17.*

12. **El Sr. Bazinas** (Secretaría) señala a la atención la nota relativa a la recomendación 18 titulada “Copia de la notificación inscrita”. La Comisión tal vez desee enmendar el apartado b) ii) para dejar claro que, si el acreedor garantizado no conoce la dirección actual del otorgante, debería tener derecho a utilizar la “última dirección” del otorgante que “conozca” o una dirección que le esté “razonablemente disponible”.

13. **El Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) expresa su apoyo a esa enmienda. El orador propone insertar una nueva disposición que exija que el acreedor garantizado envíe una copia de la notificación de cancelación a cada otorgante. La redacción revisada propuesta relativa a la dirección del otorgante también debería añadirse a esa disposición.

14. **El Sr. Weise** (American Bar Association) propone que la frase que figura al final de la recomendación se modifique para que diga “a una dirección actual del

otorgante que conozca”, por cuanto el otorgante podría tener más de una dirección.

15. **El Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que si un otorgante tiene muchas direcciones, algunas de las cuales han cambiado, el acreedor garantizado tal vez no sepa cuál es el destino que corresponda a una notificación. Una norma imperativa que obligue al acreedor garantizado que sabe que la dirección de un otorgante ha cambiado a enviar una notificación de enmienda a su dirección actual podría, por lo tanto, resultar problemática para el acreedor garantizado. Por otra parte, si al acreedor garantizado se le permitiera enviar la notificación a cualquier dirección, podría resultar arriesgado para el otorgante.

16. **El Sr. Weise** (American Bar Association) dice que supone que la referencia que se hace al final de la recomendación a un cambio de dirección del otorgante se refiere únicamente a la dirección consignada en la notificación inscrita. Ese extremo tal vez debería quedar claro en el texto.

17. **El Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) propone que la cuestión se trate en el comentario, porque hay muchas posibilidades. Por ejemplo, si una empresa con una única sede social abre una segunda oficina y traslada a muchos de sus directivos a ella, al acreedor garantizado podría resultarle difícil determinar si ha habido un cambio de dirección.

18. **El Sr. Castellano** (Italia) dice que su delegación está convencida de que se ha logrado un equilibrio óptimo en la recomendación tal como está redactada. En la recomendación no se puede prever la enorme cantidad de hipótesis posibles que, por el contrario, deberían contemplarse en el comentario.

19. **El Presidente** dice que entiende que la Comisión desea añadir las palabras “o una notificación de cancelación” después de “la notificación de enmienda” en el apartado b) ii) y sustituir la referencia a la “dirección actual” del otorgante que figura en la última frase de dicho apartado por una referencia a “la última dirección del otorgante que conozca” o “a una dirección que le esté razonablemente disponible”. En el comentario se ofrecerán otras aclaraciones sobre la cuestión de los cambios de dirección del otorgante.

20. *Queda aprobado el artículo 18, en su forma enmendada.*

21. *Quedan aprobadas las recomendaciones 19 a 21.*

22. **La Sra. Escobar** (El Salvador) pide que se aclare el requisito enunciado en el apartado b) de la recomendación 22 de que: “El registro determine y dé a

conocer públicamente el conjunto de caracteres que se habrá de utilizar”.

23. El **Presidente** dice que “el conjunto de caracteres” se refiere a la utilización, por ejemplo, del alfabeto cirílico o latino o de algún otro alfabeto.

24. El **Sr. Weise** (American Bar Association) dice que el registro podría, además, especificar qué caracteres del conjunto de caracteres de un país deben utilizarse o no. La norma relativa al idioma o los idiomas en que debe expresarse la información consignada en una notificación que se enuncia en el apartado a) de la recomendación está redactada en términos imperativos. El orador se pregunta si debería utilizarse una redacción análoga respecto del conjunto de caracteres en el apartado b).

25. El **Sr. Boettcher** (Alemania) señala que el apartado a) está dirigido a la parte que presenta la notificación, mientras que el apartado b) está dirigido al registro.

26. El **Sr. Weise** (American Bar Association) opina que el apartado b) está dirigido al autor de la inscripción y que, si ese fuera el caso, convendría señalar su carácter obligatorio claramente.

27. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que el apartado b) debe interpretarse en el sentido de que el registro está facultado para determinar y dar a conocer públicamente el conjunto de caracteres que se habrá de utilizar. El autor de la inscripción deberá entonces utilizar ese conjunto de caracteres. Por lo tanto, las palabras “que se habrá de utilizar” que figuran al final del apartado podrían sustituirse por “que deberán utilizar los autores de inscripciones”. El apartado también podría modificarse para que diga: “La información consignada en una notificación se exprese en el conjunto de caracteres que determine y dé a conocer públicamente el registro”.

28. El **Sr. Boettcher** (Alemania) expresa su preferencia por la segunda variante.

29. *Queda aprobado el artículo 22, en su forma enmendada.*

30. *Queda aprobado el capítulo III del proyecto de guía sobre el registro, en su forma enmendada.*

31. El **Presidente** invita a formular observaciones sobre el capítulo IV, relativo a la inscripción de notificaciones iniciales, que figuran en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2 y Add.3, los párrafos correspondientes del documento A/CN.9/781, y las recomendaciones 23 a 29 que figuran en el documento A/CN.9/781/Add.1.

32. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano), en relación con la última oración del párrafo 55 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, dice que en los formularios de búsqueda no hay un espacio para consignar la dirección del otorgante y que, en cualquier caso, no es necesario incluirlo. Por lo tanto, propone suprimir las palabras “y en el de la solicitud de consulta”.

33. *Así queda acordado.*

34. El **Sr. Bazinas** (Secretaría), refiriéndose a la recomendación 23, contenida en el documento A/CN.9/781/Add.1, dice que tal vez no sea necesario conservar la frase “en la misma notificación o en notificaciones diferentes” que figura al final del apartado b). De todas formas, el autor de una inscripción tiene derecho a consignar la información exigida respecto de más de un otorgante o acreedor garantizado en el espacio previsto en una o en múltiples notificaciones. Ese punto se podría poner de relieve en el comentario.

35. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) expresa su apoyo a esa propuesta

36. En cuanto al uso de las palabras “otorgante” y “acreedor garantizado” en las recomendaciones 23 a 27, el orador señala que en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* “otorgante” se define como la parte que constituye una garantía real y “acreedor garantizado” como la parte a la que se otorga la garantía real. Por otra parte, en el proyecto de guía sobre el registro, “otorgante” se define como la persona identificada en la notificación como otorgante y “acreedor garantizado” como la persona identificada en la notificación como el acreedor garantizado. En las recomendaciones 23 a 27 “otorgante” y “acreedor garantizado” se utilizan en el sentido en que los términos se definen en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. La recomendación 23, por ejemplo, exige que el identificador del otorgante se presente de una manera determinada. Ello solo puede tener sentido si se hace referencia a la parte que constituye la garantía real. Sin embargo, las referencias hechas en las recomendaciones 23 a 27 aluden al otorgante real. En el apartado a) de la recomendación 24 se indica que el identificador del otorgante sea el nombre de este. Por lo tanto, el nombre que se ha de consignar en el formulario es el nombre de la parte que constituye la garantía real. El orador sugiere que en el comentario se explique que las referencias hechas al otorgante o al acreedor garantizado en esas recomendaciones aluden al otorgante o al acreedor garantizado reales.

37. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que no debería exigirse que el registro determine si el otorgante mencionado en la notificación es el otorgante real, y que la notificación no debería invalidarse si en ella se menciona una parte distinta del otorgante real. En lo que respecta al fichero del registro, no deberían plantearse problemas si en la notificación se hiciera referencia al otorgante real o a otra parte. Por esa razón los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” se definieron simplemente por referencia a la parte indicada en la propia notificación. El orador conviene con el representante de los Estados Unidos en que sería útil explicar ese enfoque en el comentario.

38. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) comparte la opinión de que las recomendaciones 23 y 24 no representan instrucciones con destino al registro sino al autor de la inscripción. En la recomendación 24 se indica la forma correcta de consignar el nombre de un otorgante que es una persona física. Si el nombre aparece mal escrito, por ejemplo, se plantea la cuestión de si la garantía real otorgada por un otorgante sería oponible a terceros. La recomendación 27 establece normas relativas al nombre del acreedor garantizado que se ha de consignar, pero en el proyecto de guía sobre el registro “acreedor garantizado” no se define como la parte a la que se otorga la garantía real. Aunque la intención del grupo de recomendaciones, esto es, el procedimiento correcto para consignar el nombre del otorgante o del acreedor garantizado en el formulario, es evidente para la Comisión, la terminología se utiliza en consonancia con las definiciones que figuran en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

39. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) sugiere que en las recomendaciones se sustituya el término “otorgante” por una referencia a la persona que constituye la garantía real y que el término “acreedor garantizado” se sustituya por una referencia a la persona en cuyo favor se constituye esa garantía. Por otra parte, si las recomendaciones se mantuvieran sin cambios, se podría explicar en el comentario que las referencias en cuestión aluden al otorgante y al acreedor garantizado reales.

40. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) señala a la atención el párrafo 8 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54, en el que se indica que la sección sobre terminología e interpretación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* es también aplicable al proyecto de guía sobre el registro, salvo en la medida en que queda modificada en la sección sobre terminología e interpretación del proyecto de guía. El orador propone destacar en esa sección que en las recomendaciones 23

a 27 se utilizan las definiciones “otorgante” y “acreedor garantizado” que figuran en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

41. La **Sra. Walsh** (Canadá) señala que el uso de las expresiones “otorgante” y “acreedor garantizado” en el comentario refleja en términos generales su empleo en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, aunque los términos se utilizan también en algunos casos para designar a “la persona identificada en la notificación”. La oradora propone que en las definiciones de “otorgante” y de “acreedor garantizado” que figuran en el proyecto de guía para el registro la citada frase se modifique para que diga “la persona identificada o que haya de ser identificada en la notificación”. Con esa modificación, la frase “si el otorgante es una persona física” que figura al principio de la recomendación 24, por ejemplo, sería interpretada en el sentido de “si la persona que haya de ser identificada en la notificación como otorgante es una persona física”. Si la sección sobre terminología e interpretación del proyecto de guía sobre el registro es también aplicable al comentario, sería necesario precisar que, según el contexto, las expresiones “otorgante” y “acreedor garantizado” significan tanto la persona que constituye una garantía real o la persona a la que se le otorga una garantía real como la persona identificada o que haya de ser identificada en la notificación.

42. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que el hecho de que la terminología se reproduzca junto con las recomendaciones podría dar la impresión de que es aplicable solamente a las recomendaciones. Sin embargo, es también aplicable al comentario. Por otro lado, la terminología no representa un conjunto de definiciones relacionadas con un texto legislativo sino un glosario concebido para ayudar a los usuarios a comprender ciertos términos utilizados a lo largo de todo el proyecto de guía sobre el registro.

43. El **Sr. Boettcher** (Alemania) subraya la importancia de asegurar que el proyecto de guía para el registro sea lo más sencillo y fácil de leer posible para los usuarios. Un mismo término no debería tener significados diferentes en distintos contextos. El orador propone definir el término “otorgante real” en la sección de terminología y utilizarlo en las recomendaciones 23 a 27.

44. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que una alternativa a la propuesta formulada por el representante de Alemania sería utilizar los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” tal como se definen en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, en la que se hace referencia al “otorgante real” y al “acreedor garantizado real”, e introducir en el proyecto de guía sobre el registro términos

nuevos, como “persona identificada en el registro como otorgante”, “otorgante según el registro”, “persona identificada en el registro como acreedor garantizado” “acreedor garantizado según el registro”. Estos últimos términos podrían utilizarse cuando en las recomendaciones se hace referencia a la persona identificada en la notificación como otorgante o acreedor garantizado, y los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” podrían utilizarse cuando se hace referencia al otorgante o al acreedor garantizado reales.

45. El **Sr. Weise** (American Bar Association) expresa su apoyo a la observación del representante de Alemania y a la propuesta de la secretaria de utilizar el término “otorgante según el registro”.

46. La **Sra. Walsh** (Canadá) insta a la secretaria a que, al examinar el comentario, decida cómo habrán de interpretarse los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” en cada caso. La oradora dice que, como está algo preocupada por la complejidad de ese examen, es partidaria de que se indique simplemente que por lo general los términos tienen el mismo significado que en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, pero que, según el contexto, pueden referirse a la persona identificada o que haya de ser identificado en la notificación.

Se suspende la sesión a las 15.40 horas y se reanuda a las 16.10 horas.

47. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que en la mayoría de los casos las soluciones propuestas son aceptables, pero que es difícil incorporarlos en la fase actual del proceso. Por lo tanto, su delegación se inclina a favor de la solución propuesta por la representante del Canadá, esto es, señalar en la sección de terminología que los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” tienen distintos significados según el contexto. El orador opina que, en todo caso, su significado estaría claro para el lector por el contexto. En caso de duda en un caso particular, el comentario podría precisar el significado que se pretende dar a la expresión en ese caso.

48. El **Sr. Weise** (American Bar Association) dice que la utilización del término “otorgante” es muy importante en las recomendaciones. El usuario que no esté familiarizado con el término no debería verse obligado a determinar su significado según el contexto. Por consiguiente, la terminología empleada en las recomendaciones debería ser lo más precisa posible. En el caso del comentario, resulta menos arriesgado formular el tipo de declaración de carácter general propuesto por la representante del Canadá.

49. El **Sr. Castellano** (Italia) expresa su apoyo a la propuesta de la representante del Canadá. Se podrían incluir orientaciones detalladas para los usuarios que no estén familiarizados con la terminología en el comentario.

50. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que es poco probable que los lectores de las recomendaciones 23 a 27 se remitan al comentario para interpretar su significado.

51. La **Sra. Walsh** (Canadá) considera que la Comisión está de acuerdo en que en la sección de terminología debería explicarse que los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” significan, por una parte, la persona que constituye la garantía real en el caso del otorgante o la persona a la que se le otorga en el caso del acreedor garantizado y, por otra, la persona identificada o que haya de ser identificada en la notificación, según el contexto. En el comentario se explicarían ambos conceptos y se darían ejemplos. Se podría señalar también que las palabras “o que haya de ser identificada” se refieren a los problemas planteados en las recomendaciones 23 a 27.

52. El **Sr. Castellano** (Italia) y el **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) expresan su apoyo a la propuesta de la representante del Canadá.

53. El **Sr. Weise** (American Bar Association) pregunta si sería posible reemplazar en la sección de terminología las palabras “según el contexto” por referencias específicas a las recomendaciones en las que los términos se utilizan en sus distintas acepciones.

54. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) hace referencia a la nota de pie de página de la sección de terminología del documento A/CN.9/781/Add.1, en la que se indica que la sección B de la introducción de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, relativa a la terminología e interpretación, es aplicable también al proyecto de guía sobre el registro, salvo en la medida en que queda modificada por la sección B, correspondiente a terminología e interpretación, de la introducción del proyecto de guía sobre el registro. Así pues, en realidad la terminología forma parte del comentario. No obstante, en la observación que figura después de la definición del término “otorgante”, por ejemplo, podría indicarse que en las recomendaciones 23 a 27 el término significa el otorgante real o, como propone la representante del Canadá, la persona identificada o que haya de ser identificada como otorgante.

55. El **Presidente** propone que la Comisión suspenda su examen de la cuestión hasta la sesión siguiente.

56. *Así queda acordado.*

57. El **Sr. Bellenger** (Francia) expresa reservas acerca del número de apartados relativos al nombre del otorgante que figuran en la recomendación 24. Las normas se corresponden con las que normalmente son aplicables con arreglo al derecho civil de cada Estado. Por otra parte, en la nota de pie de página 3 se reconoce que la recomendación 24 es orientativa y que el Estado promulgante deberá ajustarla en función de sus convenciones en materia de nombres.

58. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) está de acuerdo con la observación formulada por el representante de Francia.

59. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) señala a la atención el párrafo 56 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, en la última oración del cual se presenta un cuadro relativo a la recomendación 24 y se indica que en él se ilustra el tipo de enfoque que podría adoptarse, pero que los Estados promulgantes deberían determinar los tipos de documentos oficiales que considerasen más apropiados, según la nomenclatura que utilizaran.

60. El **Sr. Castellano** (Italia) opina que sería preferible transferir al comentario los ejemplos que figuran en los apartados de la recomendación 24.

61. El **Sr. Boettcher** (Alemania) expresa su apoyo a esa propuesta.

62. La **Sra. Walsh** (Canadá) dice que en la recomendación 24 se dan ejemplos del grado de precisión que ha de tener la norma que regula la identificación del otorgante para que un registro sea eficaz, a fin de asegurar un entendimiento jurídico común sobre la forma de

consignar el nombre del otorgante. Unas orientaciones de ese tipo son requeridas por los autores de inscripciones y consultas y constituyen un requisito fundamental para el éxito del registro. Por otro lado, se desprende claramente de la nota de pie de página que los ejemplos son ilustrativos y que la recomendación no establece normas para todos los efectos legislativos. La consignación inexacta de los nombres de los otorgantes en el registro es la principal fuente de litigios, que frecuentemente resultan de la incapacidad del Estado para proporcionar directrices claras.

63. El **Sr. Bazinas** (Secretaría), refiriéndose a la recomendación 25, dice que el entendimiento del Grupo de Trabajo VI es que se necesita solamente un documento, ley o decreto para la identificación de las personas jurídicas, a saber, el documento, la ley o el decreto por el que se constituya la persona jurídica. Por otro lado, podrían requerirse muchos documentos diferentes para la identificación de las personas físicas y todos ellos deben ser mencionados en las normas, en consonancia con la legislación aplicable. Es por ello que la recomendación 24 contiene una lista de los documentos que podrían servir de base para identificar a dichas personas.

64. La **Sra. Walsh** (Canadá) dice que puede haber distintas fuentes oficiales del nombre de una persona física, según el país de que se trate. En consecuencia, los autores de inscripciones necesitan orientación sobre qué fuente puede considerarse fiable.

65. **El Presidente** dice que la Comisión proseguirá sus deliberaciones sobre la cuestión en la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 17.00 horas.

**Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación
de un registro de garantías reales (continuación)**

**Acta resumida de la 968ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
Viena, el lunes 15 de julio de 2013, a las 9.30 horas**

[A/CN.9/SR.968]

Presidente: Sr. Labardini Flores (Vicepresidente) (México)

Se declara abierta la sesión a las 9.40 horas.

Examen de cuestiones relacionadas con las garantías reales

a) Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación de un registro de garantías reales (continuación)

(A/CN.9/WG.VI/WP.54 y Add.1 a 4; A/CN.9/781 y Add.1 y 2; A/CN.9/764 y 767; A/CN.9/XLVI/CRP.4)

1. El **Presidente** invita a la Comisión a continuar su debate sobre el capítulo IV, relativo a la inscripción de notificaciones iniciales (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2 y Add.3) del proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales (el proyecto de guía sobre el registro) y sobre las recomendaciones 23 a 29 (A/CN.9/781/Add.1).

2. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) reitera el apoyo de su delegación a las reservas expresadas por el representante de Francia sobre el número de apartados relativos al dato identificador del otorgante en la recomendación 24. Si bien es importante disponer de un medio de identificar a las partes, no es necesario prescribir procedimientos de identificación específicos en las recomendaciones. Sería preferible describir los enfoques posibles en el comentario.

3. El **Sr. Boettcher** (Alemania) apoya las observaciones del representante de los Estados Unidos. Señala a la atención de la Comisión la recomendación 59 de la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*, relativa al dato identificador del otorgante cuando el otorgante es una persona física. En el proyecto debería incluirse una recomendación sencilla como esa, pues la cuestión se rige básicamente por la legislación nacional de cada Estado. Cualquier otra aclaración que se estime necesaria puede incluirse en el comentario.

4. El **Sr. Bellenger** (Francia) dice que en el comentario debería subrayarse la importancia de tener debidamente en

cuenta el dato identificador del otorgante cuando se trate de una persona física.

5. La **Sra. Walsh** (Canadá) dice que ha tomado nota de las observaciones relativas al enfoque innecesariamente prescriptivo adoptado en la recomendación 24. Dado que en la nota a pie de página relativa a la recomendación se señala que esta es solo de carácter ilustrativo, conviene en que los ejemplos incluidos en la recomendación deberían trasladarse al comentario. Propone que se sustituya el contenido de los apartados b), c) y d) con un texto entre corchetes en el sentido de que el Estado promulgante debería especificar la forma y el orden en que han de figurar los componentes del nombre de un otorgante y en cuáles de los espacios previstos han de insertarse. El apartado e), relativo a la fuente que debe consultarse a fin de determinar el nombre correcto de un otorgante, se basa en el supuesto de que las personas frecuentemente usan nombres distintos en contextos diferentes. La oradora propone que se sustituya ese apartado por un texto entre corchetes en el que se requiera al Estado promulgante que especifique los documentos oficiales designados como fuentes oficiales para determinar el nombre de un otorgante y proporcione otras referencias si un determinado otorgante, por ejemplo un otorgante que no sea ciudadano del Estado promulgante, no posee los documentos que se consideran indispensables. Con respecto a la nota a la Comisión que figura al final del apartado e), propone que se añada un texto entre corchetes para recordar al Estado promulgante la necesidad de formular una norma que abarque el caso de un posible cambio de nombre del otorgante.

6. El **Sr. Castellano** (Italia) está de acuerdo en que la recomendación 24 es demasiado detallada y que incumbe a los Estados promulgantes establecer las normas aplicables. Por consiguiente, apoya la propuesta de la representante del Canadá de resolver esta cuestión mediante un texto entre corchetes. Señalando a la atención de la Comisión el cuadro incluido en el párrafo 56 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, que ilustra claramente los

puntos principales, propone que el contenido del apartado e) se traslade al comentario.

7. **El Presidente**, resumiendo el debate sobre la recomendación 24, dice que la propuesta consiste en dejar sin cambios el apartado a) de la recomendación 24, incluir un texto entre corchetes en los apartados b), c) y d) para indicar que el Estado promulgante deberá especificar de qué forma y en qué orden y espacios previstos han de insertarse los componentes del nombre de un otorgante, y trasladar el texto del apartado e) al comentario indicando que ese texto es solo de carácter ilustrativo y deberá ajustarse a la luz de la legislación nacional. Además, debería añadirse un texto entre corchetes a la recomendación a fin de indicar que el Estado promulgante deberá formular una norma que prevea un eventual cambio de nombre del otorgante.

8. **El Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que, como se señaló en la reunión anterior, la utilización de los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” no siempre era coherente con su definición tal como figura en la sección sobre terminología del proyecto de guía sobre el registro.

9. **El Sr. Cohen** (Estados Unidos de América) dice que después de la última reunión un grupo de partes interesadas había revisado la utilización de los términos incluidos en las recomendaciones. Ese grupo llegó a la conclusión de que la solución basada en el contexto, consistente en que el lector aplique la definición que le indica el contexto, funciona bastante bien con respecto al término “otorgante” pero no con respecto a la expresión “acreedor garantizado” debido a que en la Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas se emplean dos definiciones distintas y considerablemente novedosas de esa expresión. Así pues, conforme a una de las recomendaciones, en la notificación debería proporcionarse el dato identificador del acreedor garantizado “o su representante”. Un segundo concepto es la distinción entre la parte a la que se otorga la garantía real y la parte que figura en la notificación, que podría describirse como el acreedor garantizado inscrito en el registro. Por tanto, las instrucciones al lector en el sentido de que aplique la definición que se ajuste al contexto podrían no resultar eficaces. Cuando se hace referencia a un acreedor garantizado económico no se requiere asistencia especial puesto que ello corresponde a la definición básica que figura en la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas*. Sin embargo, cuando surgen otras situaciones en el proyecto de guía sobre el registro, debería brindarse al lector la debida orientación. Por ejemplo, cuando la intención del texto es hacer

referencia al acreedor garantizado real o su representante, en el proyecto de guía sobre el registro puede utilizarse la frase “el acreedor garantizado o su representante”. Cuando la referencia es a la parte identificada en la notificación como acreedor garantizado, el proyecto de guía puede referirse a “la persona identificada en la notificación como el acreedor garantizado” o utilizar su propia definición del “acreedor garantizado inscrito en el registro” o del “acreedor garantizado indicado”. El orador dice que puede proporcionar a la Comisión una lista de las recomendaciones en que deberían utilizarse estos distintos términos.

10. **El Sr. Bazinas** (Secretaría) observa que en versiones anteriores se hizo referencia al “acreedor garantizado o su representante”. El Grupo de Trabajo VI ha acordado que es suficiente hacer referencia al “acreedor garantizado” en el entendimiento de que, a la luz de la definición contenida en el proyecto de guía sobre el registro, el acreedor garantizado puede ser el acreedor garantizado económico o su representante. El orador pregunta si el representante de los Estados Unidos estima que en el proyecto de guía deberían reflejarse los tres conceptos, a saber, el acreedor garantizado, el acreedor garantizado efectivo, que puede ser el acreedor garantizado económico o su representante, y el acreedor garantizado identificado en la notificación.

11. La **Sra. Sabo** (Canadá), si bien agradece los esfuerzos de la delegación de los Estados Unidos por llegar a un texto más preciso, su delegación estima que hay que confiar en el lector para que haga las distinciones que proceda. Habida cuenta de que sería necesario modificar no solo las recomendaciones sino también el comentario, el riesgo de que se cometan errores e imprecisiones es bastante grande.

12. **El Sr. Cohen** (Estados Unidos de América) dice que no pretende poner en tela de juicio la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo con respecto a la frase “el acreedor garantizado o su representante”, sino simplemente tener en cuenta los problemas que podrían plantearse a los lectores de las recomendaciones que no estén familiarizados con los distintos conceptos. La falta de referencia a un representante podría conducir a una conclusión errada, por ejemplo con respecto a la recomendación 27, relativa al dato identificador del acreedor garantizado. Su delegación está dispuesta a presentar lo antes posible a la Comisión una propuesta concreta sobre la cuestión.

13. **El Presidente** invita a la delegación de los Estados Unidos a que presente una propuesta.

14. La **Sra. Walsh** (Canadá) espera que los Estados Unidos no propongan el uso de una terminología distinta en las recomendaciones y el comentario. En la reunión anterior, su delegación propuso que se señalara simplemente que los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” tenían por lo general el mismo significado que en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* pero que, según el contexto, podían también referirse a la persona identificada o que será identificada en la notificación.

15. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que el Grupo de Trabajo aprobó la recomendación 27 sin hacer referencia al representante aunque en una versión anterior existía esa referencia. El Grupo de Trabajo aprobó la versión posterior en el entendimiento de que al acreedor garantizado que haga la inscripción decidirá si coloca su propio nombre o el de su representante.

16. La **Sra. Walsh** (Canadá) recuerda a la Comisión la nota incluida en la sección sobre terminología, en la que se señala que la sección sobre terminología e interpretación de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* se aplica también al proyecto de guía sobre el registro, salvo en la medida en que la modifique la sección sobre terminología e interpretación del proyecto de guía sobre el registro. El problema que dio lugar al debate estriba en que en algunos casos las definiciones de “otorgante” y de “acreedor garantizado” en esta última sección habían reemplazado a las contenidas en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* en vez de simplemente suplementarlas. Su delegación propuso la frase “la persona identificada en la notificación” a fin de resolver ese problema.

17. El **Sr. Weise** (American Bar Association) observa que los representantes de los Estados Unidos y del Canadá están razonablemente bastante preocupados por asegurarse de que se aclare el significado de los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” y evitar cualquier confusión. El orador sugiere que podría llegarse a un acuerdo sobre la adopción del enfoque más adecuado en el marco de consultas oficiosas.

18. El **Sr. Castellano** (Italia) apoya esa sugerencia.

19. El **Presidente** insta a las partes interesadas a que celebren consultas sobre la cuestión y presenten sus conclusiones a la Comisión.

20. A continuación, invita a la Comisión a que prosiga el debate sobre las propuestas relativas a la recomendación 24.

21. La **Sra. Walsh** (Canadá) entiende que el nuevo apartado b) indicaría entre corchetes que el Estado

promulgante debe formular una norma según la cual se especifique qué componentes del nombre de un otorgante y en qué orden y espacios previstos han de incluirse; que el apartado c) indicaría entre corchetes las fuentes oficiales para determinar el nombre del otorgante; y que el apartado d) indicaría entre corchetes que el Estado promulgante debería formular una norma que abarque el caso de un eventual cambio de nombre del otorgante.

22. El **Presidente** dice que si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el texto en el sentido indicado por la representante del Canadá.

23. *Queda aprobada la recomendación 24 en su forma enmendada.*

24. El **Presidente** entiende que la Comisión desea omitir la frase “en la misma notificación o en notificaciones diferentes” que figura al final del apartado b) de la recomendación 23.

25. *Queda aprobada la recomendación 23 en su forma enmendada.*

26. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) observa que, conforme a una propuesta de la representante del Canadá, la recomendación 25 debería dividirse en dos apartados a fin de que sea coherente con la recomendación 24. El primer apartado diría que el dato identificador del otorgante es el nombre del otorgante y el segundo apartado diría que el nombre del otorgante es el nombre que se indique como su nombre en el documento, la ley o el decreto reciente por el [la] que se constituya dicha persona jurídica.

27. El **Presidente** entiende que la Comisión desea aprobar la recomendación 25 sobre la base de esa reformulación.

28. *Queda aprobada la recomendación 25 en su forma enmendada.*

29. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que la recomendación 26 se presenta entre corchetes porque es de carácter ilustrativo y el Estado promulgante tal vez desee ajustar su contenido de acuerdo a su legislación y añadir otros casos especiales. El apartado a) se refiere a personas que están sometidas a un procedimiento de insolvencia y en el comentario se explica que el otorgante puede ser la persona sometida a un procedimiento de insolvencia o el representante de la insolvencia. El orador señala a la atención de la Comisión la nota relativa a la recomendación, que sugiere varias enmiendas a fin de tener en cuenta diversas eventualidades. La nota incluye un posible texto enmendado del apartado b), así como una nueva redacción del apartado c). Además de la enmienda a la recomendación 24, la Comisión tal vez desee considerar

una posible reformulación de la recomendación 26 en términos más generales y decidir si las diversas cuestiones que esta recomendación plantea deberían abordarse en el comentario.

30. El **Sr. Boettcher** (Alemania) dice que las cuestiones planteadas en la nota a la Comisión son importantes y deberían tomarse en consideración. Sin embargo, si esas cuestiones se incluyen en la recomendación el contenido de esta se complicará innecesariamente, en tanto que su propósito es solo de carácter ilustrativo. Por tanto, propone que las cuestiones tratadas en la nota se trasladen al comentario.

31. El **Sr. Bellenger** (Francia) apoya la propuesta del representante de Alemania. Los casos a los que se refiere la nota no pueden darse con arreglo a la ley francesa ni a la de una buena parte de los Estados que utilizarán la Guía para la creación de un registro.

32. La **Sra. Walsh** (Canadá) está de acuerdo con el contenido de las soluciones propuestas en la nota a la recomendación 26 y no se opone a la propuesta de que se trasladen al comentario.

33. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) apoya las opiniones expresadas por los oradores anteriores. La recomendación debería modificarse a fin de que sea coherente con el enfoque adoptado en el caso de la recomendación 24.

34. El **Presidente** entiende que la Comisión conviene en que la recomendación 26 contenga un texto entre corchetes en el que se pida al Estado promulgante que especifique el dato identificador del otorgante en casos especiales. Los ejemplos citados en la recomendación, en su forma enmendada en el sentido mencionado en la nota a la Comisión, se incluirán en el comentario.

35. *Queda aprobada la recomendación 26 en su forma enmendada.*

Se suspende la sesión a las 10.50 horas y se reanuda a las 11.15 horas.

36. El **Presidente** entiende que la Comisión desea aprobar la recomendación 27.

37. *Queda aprobada la recomendación 27.*

38. El **Sr. Bazinas** (Secretaría), haciendo la presentación de la nota a la Comisión relativa a la recomendación 28, dice que las palabras “si la ley no dispone otra cosa” que figuran en los apartados b) y c) deberían suprimirse. La referencia a la descripción de los bienes gravados “de forma suficiente para poder identificarlos” en el apartado a) refleja la norma aplicada en la *Guía sobre las*

Operaciones Garantizadas. Si se incluyen las palabras “si la ley no dispone otra cosa” se podría dar inadvertidamente la impresión de que hay excepciones a esa norma. Sin embargo, la Comisión tal vez desee examinar la posibilidad de insertar en los apartados b) y c) la frase “si no se indica otra cosa en la notificación” a fin de señalar que las partes pueden excluir ciertos bienes incluidos en una determinada categoría.

39. El **Sr. Weise** (American Bar Association) es partidario de omitir las palabras “si la ley no dispone otra cosa” en los apartados b) y c). Estima innecesario añadir las palabras “si no se indica otra cosa en la notificación” pues si la notificación excluye ciertos bienes, la descripción es, por definición, de carácter no genérico.

40. El **Presidente** entiende que la Comisión desea omitir las palabras “si la ley no dispone otra cosa”.

41. *Queda aprobada la recomendación 28 en su forma enmendada.*

42. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que el apartado c) de la recomendación 29 está entre corchetes porque su aplicación depende de si un Estado promulgante permite o no que un autor de la inscripción elija el plazo de vigencia de una notificación y de si la notificación debería o no incluir un importe máximo por el que puede ejecutarse la garantía real. La intención es dejar el texto entre corchetes en la versión final, junto con las explicaciones que figuran en las notas a pie de página.

43. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) propone que en el apartado a) se sustituyan las palabras “una notificación de enmienda que modifique” por “una notificación de enmienda que cambie”.

44. Propone asimismo que al final del apartado a) se añada la frase siguiente: “y utilizando la lógica de búsqueda correcta”. De esta forma, una búsqueda o una inscripción solo serán efectivas si el autor de la búsqueda utiliza el fichero del registro público y aplica la lógica de búsqueda oficial.

45. El **Sr. Castellano** (Italia) dice que si bien no se opone a la segunda enmienda propuesta, tiene reservas con respecto a la expresión “lógica de búsqueda”. Pregunta si esta expresión se ha utilizado en alguna otra parte del proyecto de guía sobre el registro. De no ser así, sería necesario incluir una explicación en el comentario.

46. La **Sra. Walsh** (Canadá) dice que tiene reservas análogas con respecto a la enmienda propuesta. El apartado a) se refiere a una búsqueda que utiliza como

criterio el dato identificador correcto del otorgante. No queda claro por qué ese criterio no es adecuado.

47. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) dice que el término “lógica de búsqueda” se usa en la recomendación 35 con respecto a los resultados de una consulta. Sin embargo, no desea insistir en esta propuesta de enmienda. La cuestión puede resolverse en el comentario.

48. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que cuando la Comisión examine el comentario sobre la recomendación 35 tal vez desee añadir algunas aclaraciones con respecto a la expresión “lógica de búsqueda”.

49. El **Presidente** entiende que la Comisión desea sustituir la palabra “modifique” por “cambie” en el apartado a).

50. *Queda aprobada la recomendación 29 en su forma enmendada.*

51. El **Presidente** señala a la atención de la Comisión el párrafo 44 del documento A/CN.9/781, en el que se señala que si la Comisión modifica la recomendación 26, el párrafo 68 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2 debería sustituirse por los tres nuevos párrafos 68 a 70. El texto de estos párrafos se consigna en el párrafo 44.

52. A la luz de la decisión de la Comisión con respecto a la recomendación 28, se suprimiría el párrafo 51 del documento A/CN.9/781.

53. *Queda aprobado el capítulo IV del proyecto de guía sobre el registro en su forma enmendada.*

54. El **Presidente** pregunta si ha habido progresos en las consultas sobre la recomendación 13, relativa al plazo de vigencia de la inscripción de una notificación, que quedó pendiente.

55. La **Sra. Walsh** (Canadá) dice que el grupo de consulta redactó una versión revisada de la recomendación. Recuerda que se expresó preocupación con respecto a la variante C y, por extensión, a la variante A debido a la posibilidad circunvenir el plazo máximo de inscripción de una notificación mediante la inscripción de una notificación de enmienda poco tiempo después de inscribir la notificación inicial. La extensión del plazo máximo resultante se considera incompatible con la política de fijar un plazo de vigencia máximo en la guía. Al mismo tiempo, debería mantenerse cierto grado de flexibilidad para que los acreedores garantizados puedan renovar sus inscripciones antes de que expire el plazo de vigencia de la notificación inicial. La solución propuesta consiste en estipular, en las variantes A y C, que la inscripción

registral de una notificación de enmienda por la que se prorrogue el plazo de vigencia de la inscripción registral solo debería ser posible durante un período breve antes de que expire el plazo en curso. Además, se uniformó el texto de las distintas variantes.

56. Refiriéndose en primer lugar al apartado a) de la variante A, la oradora dice que el grupo de consulta propone añadir las palabras “por ejemplo, cinco años” después de “Estado promulgante”. El texto revisado del apartado b) sería el siguiente: “El plazo de vigencia de la inscripción registral se pueda prorrogar antes de su expiración durante [un plazo breve, por ejemplo, de seis meses] antes de su expiración.” El apartado c) se sustituiría por el texto siguiente: “La inscripción registral de una notificación de enmienda por la que se prorrogue el plazo de vigencia prorrogará dicho plazo durante [el plazo especificado en el apartado a)] a partir de la fecha en que expire el plazo inicial.”

57. Pasando a la variante B, la oradora dice que el grupo propone insertar las palabras “por el autor de la inscripción” después de “durante el plazo especificado” en el apartado a). Tanto la variante B como la variante C permiten reducir el plazo de vigencia inicial mediante la inscripción de una notificación de enmienda. A juicio del grupo, la posibilidad de reducir ese plazo no es muy útil en la práctica en la medida en que una notificación de cancelación tendría el mismo resultado. Por tanto, el grupo propone que se supriman las palabras “o reducirse” en el apartado b) y explicar el razonamiento conexo en el comentario. Las palabras “que expire” en el apartado b) se sustituirían por “su expiración”. El texto del apartado c) se reemplazaría por el siguiente: “La inscripción registral de una notificación de enmienda por la que se prorrogue el plazo de vigencia prorrogará dicho plazo durante el tiempo especificado por el autor de la inscripción en la notificación de enmienda a partir de la fecha en que expire el plazo inicial.”

58. Con respecto a la variante C, el grupo propone, como en la variante B, insertar las palabras “por el autor de la inscripción” después de “durante el plazo especificado” en el apartado a). Propone asimismo suprimir la palabra “como,” antes de “por ejemplo”. El texto revisado del apartado b) sería: “El plazo de vigencia se podrá prorrogar antes de su expiración durante [un plazo breve, por ejemplo de seis meses] mediante la inscripción de una notificación de enmienda en la que se indique en el espacio previsto un nuevo plazo de vigencia que no sea superior [al plazo máximo especificado en el apartado a)].” El apartado c) se sustituiría por un texto idéntico al propuesto para el apartado c) de la variante B.

59. El **Sr. Boettcher** (Alemania) propone que se añadan las palabras “que especifique la ley del Estado promulgante” después de las palabras “por ejemplo de seis meses” en el apartado b) de las variantes A y C.

60. El **Presidente** entiende que la Comisión desea aprobar la versión de la recomendación 13 propuesta por el grupo de consulta, con la modificación propuesta por el representante de Alemania.

61. *Queda aprobada la recomendación 13 en su forma enmendada.*

62. El **Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre el capítulo V, relativo a la inscripción de notificaciones de enmienda y de cancelación, que figura en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, así como sobre los párrafos correspondientes del documento A/CN.9/781 y las recomendaciones 30 a 33 contenidas en el documento A/CN.9/781/Add.1.

63. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano), refiriéndose al párrafo 67 del documento A/CN.9/781, se declara confundido por la referencia, en la segunda oración, al rechazo de la notificación de cancelación “si el número de inscripción no coincide exactamente con el dato identificador del otorgante”. Sugiere que nunca puede esperarse que el número de inscripción sea el mismo que el dato identificador, pues son dos componentes completamente distintos de una notificación de inscripción. Propone que se modifique la frase para que diga “si el dato identificador del otorgante indicado en la notificación de cancelación no es idéntico al dato identificador del otorgante que figura en la notificación de inscripción a la que se refiere”.

64. *Así queda acordado.*

65. *Queda aprobada la recomendación 30.*

66. El **Sr. Wiese** (American Bar Association) apoya la sugerencia que figura en la nota a la Comisión incluida después de la recomendación 31 en el sentido de que se revisen tanto la variante A como la B de modo que indiquen que el acreedor garantizado mencionado en múltiples notificaciones inscritas puede modificar, o pedir al registro que modifique “su información” en vez de “la información relativa al acreedor garantizado en todas esas notificaciones”.

67. *Queda aprobada la recomendación 31 en su forma enmendada.*

68. *Queda aprobada la recomendación 32.*

69. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) señala a la atención de la Comisión el apartado a) de la recomendación 33, según el

cual el acreedor garantizado estará “obligado a inscribir” una notificación de enmienda o de cancelación en determinadas circunstancias. Si la Comisión decide mantener esa redacción, podría explicarse en el comentario que las palabras “obligado a inscribir” tienen por objeto aclarar que no puede considerarse que el acreedor garantizado haya cumplido su obligación simplemente por haber “presentado” una notificación, sin asegurarse de que la notificación se inscribirá realmente y no será rechazada por alguna de las razones enunciadas en la recomendación 8. La definición de “notificación” que figura en la sección sobre terminología se refiere a una comunicación por escrito dirigida al registro. Según la recomendación 6, apartado a), “toda persona” puede “presentar una notificación para su inscripción”, y según la recomendación 9, “toda persona” puede “presentar una solicitud de consulta”. Además, a raíz de una enmienda adoptada por la Comisión, en la sección sobre terminología, el “autor de una inscripción” es la persona que presenta al registro el formulario registral establecido para las notificaciones y la “inscripción” se define como la incorporación al fichero registral de la información consignada en una notificación. Si la Comisión decide mantener la frase “obligado a inscribir” en vez de “obligado a presentar” una notificación de enmienda o de cancelación, tal vez desee incluir una aclaración en el comentario. En el comentario también podría explicarse que, si bien la palabra “presentar” sería más apropiada en el caso de una notificación en papel, la palabra “inscribir” sería probablemente más apropiada en el caso de notificaciones electrónicas.

70. La **Sra. Sabo** (Canadá) dice que su delegación desea mantener el texto de la recomendación 33 en su forma actual.

71. *Queda aprobada la recomendación 33.*

72. *Queda aprobado el Capítulo V del proyecto de guía sobre el registro en su forma enmendada.*

73. El **Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre el capítulo VI, relativo a los criterios de consulta y resultado de la consulta, que figura en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4, así como sobre los párrafos correspondientes del documento A/CN.9/781 y las recomendaciones 34 y 35 contenidas en el documento A/CN.9/781/Add.1.

74. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano), dice que la expresión “lógica de búsqueda” utilizada en la recomendación 35, apartado b), es un término técnico. Por tanto, propone que

se supriman las palabras “o lógica de búsqueda” que figuran entre corchetes.

75. Los párrafos 47 y 48 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4 también hacen referencia a la “lógica de búsqueda” y al “sistema de registro” como si fueran intercambiables. El orador propone que se reemplace en cada caso “lógica de búsqueda” por “sistema de registro”.

76. El **Sr. Weise** (American Bar Association) propone que en el comentario se aclare que todas las referencias a

la obtención de información por medio de búsquedas guardan relación con búsquedas realizadas por la oficina del registro o de conformidad con el sistema utilizado por la oficina del registro. Dado que algunas oficinas de registro permiten que su propia metodología de búsqueda de datos sea utilizada por terceros, una búsqueda hecha por un tercero podría arrojar información distinta de la que arrojaría si la búsqueda hubiese sido hecha por la oficina del registro.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

**Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación
de un registro de garantías reales (continuación)**

**Acta resumida de la 969ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
Viena, el lunes 15 de julio de 2013, a las 14.00 horas**

[A/CN.9/SR.969]

Presidente: Sr. Labardini Flores (Vicepresidente) (México)

Se declara abierta la sesión a las 14.10 horas.

Examen de cuestiones relacionadas con las garantías reales

a) Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación de un registro de garantías reales (continuación)
(A/CN.9/WG.VI/WP.54 y Add.1 a 4; A/CN.9/781 y Add.1 y 2; A/CN.9/764 y 767; A/CN.9/XLVI/CRP.4)

1. **El Presidente** invita a la Comisión a finalizar su examen del capítulo VI del proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales (el proyecto de guía sobre el registro) y de las recomendaciones 34 y 35.

2. *Queda aprobada la recomendación 34.*

3. **El Presidente** entiende que la Comisión desea suprimir las palabras “lógica de búsqueda” que figuran entre corchetes en la recomendación 35.

4. *Queda aprobada la recomendación 35 en su forma enmendada.*

5. **El Presidente** entiende que la Comisión desea hacer suya la propuesta del representante del Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano de sustituir la expresión “lógica de búsqueda” en los párrafos 46 y 47 del documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4 por una referencia al sistema del registro, así como la propuesta del representante de la American Bar Association de que se aclaren en el comentario las referencias a la recuperación de información por medio de búsquedas.

6. *Así queda acordado.*

7. *Queda aprobado el capítulo VI del proyecto de guía sobre el registro en su forma enmendada.*

8. **El Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre el capítulo VII, relativo a las tasas de inscripción y de consulta (A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4),

sobre el párrafo correspondiente del documento A/CN.9/781 y sobre la recomendación 36 contenida en el documento A/CN.9/781/Add.1.

9. *Queda aprobada la recomendación 36.*

10. *Queda aprobado el capítulo VII del proyecto de guía sobre el registro en su forma enmendada.*

11. **El Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre el anexo II del proyecto de guía sobre el registro, que contiene ejemplos de los formularios de registro (A/CN.9/781/Add.2).

12. El Sr. **Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) dice que la enmienda a la definición de “dirección” en la sección sobre terminología debería reflejarse en los formularios de registro. Por ejemplo, los recuadros del formulario I, sección A.1, no contienen ninguna referencia a una calle. Propone que el encabezamiento del recuadro que figura en la segunda línea, donde se hace referencia a “Apartado postal (si corresponde)” se modifique para que diga “Calle o apartado postal (si corresponde)”. Además, dado que la Comisión suprimió, en la definición de “dirección”, las palabras “que sirva para comunicar información”, en el recuadro correspondiente a “Dirección electrónica o de otro tipo (si corresponde)” debería figurar “Dirección electrónica (si corresponde)”.

13. Si el otorgante es una persona jurídica, se dispone de un espacio para “Información adicional sobre el otorgante”. Ni en la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas (Guía sobre las Operaciones Garantizadas)* ni en el proyecto de guía sobre el registro se requiere información adicional sobre un otorgante que sea una persona jurídica. En consecuencia, el orador propone que se suprima dicho espacio.

14. Por último, dice que las casillas delante de “Persona física” y “Persona jurídica” en todos los formularios podrían resultar confusas para los usuarios. Por ejemplo, si se inserta información en los recuadros relativos a una “persona física” pero no se selecciona la casilla, podría

suponerse que el registro no está obligado a rechazar el formulario. En consecuencia, el orador propone que se supriman esas casillas, al menos en la notificación inicial. Sin embargo, las casillas pueden mantenerse en el recuadro 3 de los formularios, relativo a los casos especiales relacionados con otorgantes, pero en ese caso sugiere que el texto figure entre corchetes.

15. La **Sra. Walsh** (Canadá) apoya la propuesta de incluir entre corchetes el texto que figura en el recuadro 3 relativo al otorgante. Propone además que se incluya una nota a pie de página con una referencia a la parte pertinente del comentario y a la posible necesidad de añadir otros casos especiales.

16. Apoya asimismo la propuesta de suprimir las casillas delante de “Persona física” y “Persona jurídica”.

17. La oradora propone también que se supriman las secciones A.2 y B.2, que se utilizarían solo si existe más de un otorgante o acreedor garantizado. Pueden reemplazarse por una nota a pie de página en la que se indique que cuando haya más de un otorgante o acreedor garantizado, el Estado promulgante debería incluir recuadros en sus formularios en papel o electrónicos donde los autores de una inscripción puedan insertar la información adicional necesaria.

18. El **Presidente** entiende que la Comisión está de acuerdo en hacer las siguientes modificaciones al formulario I (notificación inicial): suprimir las casillas delante de “Persona física” y “Persona jurídica” en las secciones A y B; modificar las referencias a “Apartado postal (si corresponde)” en las secciones A y B para que digan “Calle o apartado postal (si corresponde)”; modificar la referencia a “Dirección electrónica o de otro tipo (si corresponde)” en las secciones A y B para que diga “Dirección electrónica (si corresponde)”; suprimir el recuadro titulado “Información adicional sobre el otorgante” que figura a continuación de “Persona jurídica” en la sección A; incluir entre corchetes el recuadro correspondiente a casos especiales relacionados con un otorgante en la sección A y añadir una nota a pie de página con una referencia al comentario; suprimir las secciones A.2 y B.2 y reemplazarlas por la nota a pie de página propuesta por la representante del Canadá.

19. *Así queda acordado.*

20. La **Sra. Walsh** (Canadá) señala que deberían hacerse enmiendas análogas respecto de las casillas correspondientes del formulario II, relativo a las notificaciones de enmienda.

21. *Así queda acordado.*

22. El **Sr. Weise** (American Bar Association) dice que la sección J del formulario II, titulada “Prórroga o reducción del plazo de vigencia de la inscripción” debería modificarse a la luz de las enmiendas a la recomendación 13 aprobadas en la reunión anterior. La validez de la notificación dependerá de si el Estado promulgante aplica la variante A, B o C.

23. La **Sra. Walsh** (Canadá) propone que se supriman las palabras “o reducción” en el título.

24. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) observa que la nota a pie de página que figura en la sección J indica que la sección se refiere solo a los casos en que se aplique la variante B o la variante C de la actual recomendación 13.

25. El **Sr. Weise** (American Bar Association) dice que, a su juicio, la variante A debería quedar abarcada en la sección J dado que un acreedor garantizado necesita poder prorrogar el plazo de vigencia de la notificación con arreglo a esa variante. Con respecto a la variante C, estima que sería más seguro que la oficina del registro calcule el plazo de prórroga fijo a partir de la fecha de expiración del plazo en curso.

26. La **Sra. Walsh** (Canadá), refiriéndose nuevamente a la notificación inicial, señala que en la sección D del formulario I, relativa al plazo de vigencia de la inscripción, se indica que la notificación sería válida hasta una determinada fecha. En cambio, algunos sistemas de registro prevén que la notificación es válida durante un período especificado, por ejemplo un cierto número de años. En consecuencia, propone que se modifique el texto de la sección D del formulario I para que diga lo siguiente: “La presente notificación será válida durante un plazo de [x años y x meses] hasta el (día/mes/año)”. También sería preferible, en la sección J del formulario II, sustituir la frase “La presente notificación será válida hasta el (día/mes/año)” por “La presente notificación será válida durante un período prorrogado de [x años y x meses]”. La oradora conviene en que el plazo automático establecido por el Estado promulgante conforme a la variante A debería especificarse en el formulario. Sin embargo, como ese plazo se generaría automáticamente, el autor de la inscripción no podría insertar ningún otro dato.

27. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que la nota a pie de página que figura en la sección D del formulario I puede modificarse de la forma siguiente: “Si un Estado promulgante decide aplicar la variante A de la recomendación 13, el plazo de duración de la inscripción será automáticamente generado por el registro”. La nota a pie de página de la sección J, en su forma enmendada, podría decir lo siguiente: “Si un Estado promulgante decide

aplicar la variante A de la recomendación 13, el plazo de duración de la prórroga será automáticamente generado por el registro”.

28. El **Sr. Weise** (American Bar Association) apoya las propuestas de la representante del Canadá y de la secretaria. Pregunta si las fechas o plazos de prórroga pueden ser automáticamente generados en un sistema no electrónico a fin de que estén disponibles de inmediato a los autores de una consulta. Propone asimismo que se añada un texto a las notas a pie de página para indicar que, cuando un Estado promulgante decida aplicar la variante C, el programa informático esté configurado para rechazar un plazo de un número de años que exceda del plazo máximo permitido por el Estado.

29. La **Sra. Walsh** (Canadá) expresa su apoyo a esa propuesta. Con respecto a la generación automática de fechas y plazos de prórroga, sugiere que en las secciones pertinentes de los formularios se incluya una nota que indique que “Este espacio es para uso exclusivo de la oficina del registro”.

30. El **Presidente** entiende que la Comisión desea modificar el texto de la sección D del formulario I de la forma siguiente: “La presente notificación será válida durante un plazo de [x años y x meses] hasta el (día/mes/año)”. La nota a pie de página en la sección D se modificaría para que diga: “Si un Estado promulgante decide aplicar la variante A de la recomendación 13, el plazo de duración de la prórroga será automáticamente generado por el registro”. En la nota a pie de página también se indicarían las medidas que han de adoptarse cuando un Estado promulgante decida aplicar la variante C.

31. Con respecto a la sección J del formulario II, el orador entiende que la Comisión desea suprimir las palabras “o reducción” en el título y modificar el texto del recuadro para que diga: “La presente notificación será válida durante un plazo de [x años y x meses] hasta el (día/mes/año)”. El texto de la nota a pie de página de la sección J sería el siguiente: “Si un Estado promulgante decide aplicar la variante A de la recomendación 13, el plazo de duración de la prórroga será automáticamente generado por el registro”. En la nota se indicaría asimismo que, cuando un Estado promulgante decida aplicar la variante C, el programa informático debería configurarse de modo que rechace un plazo de un número de años que exceda del plazo máximo permitido por el Estado.

32. La **Sra. Walsh** (Canadá) propone que en los formularios I y II se especifique el plazo máximo para la variante C.

33. El **Sr. Weise** (American Bar Association) dice que un sistema electrónico automáticamente rechazaría un plazo inaceptable. En el caso de un sistema basado en papel, debería alertarse al autor de una inscripción respecto del plazo legalmente establecido. Sugiere que la secretaria redacte tres textos alternativos entre corchetes para la sección D del formulario I y la sección J del formulario II en los que se indiquen las disposiciones de la recomendación 13 en relación con las variantes A, B y C.

34. El **Sr. Castellano** (Italia) es partidario de que las tres variantes se describan en los formularios. En particular, el plazo máximo establecido debería especificarse cuando proceda.

35. El **Presidente** entiende que la Comisión desea modificar la sección D del formulario I y la sección J del formulario II a fin de reflejar las variantes A a C de la recomendación 13. En el comentario se abordarían las cuestiones de política que podrían surgir en el caso de un sistema basado en papel cuando el autor de la inscripción indique un período que exceda del plazo máximo legalmente establecido.

36. *Así queda acordado.*

37. El **Presidente** invita a la Comisión a hacer observaciones sobre el formulario III, relativo a las notificaciones de cancelación.

38. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) propone que se sustituya el texto del segundo recuadro, “Número de inscripción de la notificación inicial que ha de cancelarse”, por el siguiente texto basado en la recomendación 32: “Núm. de inscripción de la notificación inicial a que se refiere la cancelación”.

39. *Así queda acordado.*

40. El **Presidente**, pasando al formulario IV, relativo a una notificación de enmienda con arreglo a una orden judicial o administrativa”, dice que el texto “Número de inscripción de la notificación inicial” se reemplazaría por “Núm. de inscripción de la notificación inicial a que se refiere la cancelación” y se suprimirían las casillas delante de “Persona física” y “Persona jurídica” en las secciones C y D. En las secciones A y D se sustituiría la frase “Apartado postal (si corresponde)” se revisaría para que diga “Calle o apartado postal (si corresponde)”. Las referencias a “Dirección electrónica o de otro tipo (si corresponde)” en las secciones A y D se modificarían para que digan “Dirección electrónica (si corresponde)”. Se suprimiría el recuadro “Información adicional sobre el otorgante” en la sección D. El recuadro relativo a casos

especiales en la sección D se pondría entre corchetes y se insertaría una nota a pie de página con una referencia al comentario pertinente. Las palabras “o reducción” se suprimirían del texto en la sección G y se modificaría la nota a pie de página en la forma acordada previamente.

41. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) dice que es improbable que un otorgante pida una prórroga del plazo de vigencia en las circunstancias previstas en el formulario IV. Por tanto, propone que se suprima la frase “Prórroga o reducción del” en la sección G.

Se suspende la sesión a las 15.35 horas y se reanuda a las 16.05 horas.

42. El **Presidente** propone que se suprima toda la sección G del formulario IV.

43. *Así queda acordado.*

44. El **Presidente**, refiriéndose al formulario V, relativo a la notificación de cancelación con arreglo a una orden judicial o administrativa, dice que se harán modificaciones similares a las propuestas para el formulario IV en los recuadros correspondientes a la dirección y a la dirección electrónica en la sección A. Además, el texto “Núm. de inscripción de la notificación inicial que ha de cancelarse”, se modificará para que diga “Núm. de inscripción de la notificación inicial a que se refiere la cancelación”.

45. Pasando al formulario VI, relativo a la solicitud de consulta, el orador dice que las casillas delante de “Persona física” y “Persona jurídica” deberían suprimirse.

46. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) propone que se incluya un recuadro por separado para los autores de búsquedas que presenten una solicitud de búsqueda en papel en la que indiquen la persona y la dirección a las que los resultados de la búsqueda han de enviarse por correo.

47. *Así queda acordado.*

48. El **Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre el formulario VII, relativo a los resultados de la consulta.

49. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) dice que, según la nota a pie de página, el resultado de una consulta puede mostrar toda la información contenida en las notificaciones recuperadas según el diseño del registro. Por otra parte, la recomendación 35, apartado a), requiere que se consigne toda la información de cada notificación inscrita que coincida con el criterio de consulta especificado. El orador

propone que se modifique la nota a pie de página para que refleje el contenido de la recomendación 35.

50. La **Sra. Walsh** (Canadá) apoya esa propuesta.

51. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que el Grupo de Trabajo ha considerado, en relación con el formato de presentación, si todos los resultados de una solicitud de consulta deberían enumerarse inmediatamente o si debería proporcionarse un cuadro que permita consultas adicionales.

52. La **Sra. Walsh** (Canadá) dice que este último enfoque sería apropiado en un sistema electrónico en el que el autor de la búsqueda puede pulsar una tecla para obtener información adicional sobre una cuestión. En un sistema basado en papel, el autor de la búsqueda necesitaría regresar al registro para obtener detalles suplementarios. En la nota a pie de página puede indicarse que la presentación de la información requerida por la recomendación 35 podría ser diferente según el sistema de registro de que se trate.

53. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que el resultado de la búsqueda proporcionado al autor de la consulta no debería requerir una segunda solicitud de información más detallada. En la nota a pie de página puede indicarse el enfoque que ha de adoptarse respectivamente en los sistemas electrónicos y en papel.

54. El **Presidente** dice que la nota a pie de página se enmendará para tener en cuenta las diversas propuestas presentadas.

55. Invita a la Comisión a hacer observaciones sobre el formulario VIII, relativo al rechazo de una solicitud de inscripción o de consulta.

56. El **Sr. Weise** (American Bar Association), observa que en la sección B.1 hay una sola casilla para “El dato identificador o la dirección del otorgante” y para “El dato identificador o la dirección del acreedor garantizado” y sugiere que debería haber dos casillas en cada caso, una para el dato identificador y otra para la dirección.

57. En la sección B.2 figura la casilla “Información pertinente a la adición, supresión o modificación”, lo que permite suponer que el registro determinaría la pertinencia de la información proporcionada. El orador propone que se suprima la palabra “pertinente” y se incluyan casillas por separado para “Adición”, “Supresión” y “Modificación”.

58. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) propone que el texto “El número de inscripción de la notificación inicial” en la sección B.2 se sustituya por “El número de inscripción de

la notificación inicial a que se refiera la enmienda”. El texto “El número de inscripción de la notificación inicial” que figura en la sección B.3 también debería modificarse para que diga: “El número de inscripción de la notificación inicial a que se refiera la cancelación”.

59. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que, en consonancia con la recomendación 32, en la que no figura la palabra “inicial”, el texto de la versión enmendada debería ser: “El número de inscripción de la notificación a que se refiere la cancelación”.

60. La **Sra. Walsh** (Canadá) dice que el número de inscripción es siempre el que se asigna a la notificación inicial.

61. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano) dice que, si bien la adición de la palabra “inicial” es redundante porque “número de inscripción” se define en la sección sobre terminología como “el número único asignado por el registro a una notificación inicial”, concuerda con la representante del Canadá en que debería incluirse en la versión revisada de la sección B.3.

62. El **Presidente** entiende que la Comisión desea aprobar las modificaciones propuestas por los representantes de la American Bar Association y del Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano.

63. *Así queda acordado.*

64. El **Presidente**, refiriéndose al formulario II, relativo a las notificaciones de enmienda, propone que se modifique

la frase “Núm. de inscripción de la notificación inicial” para que diga “Núm. de inscripción de la notificación inicial a que se refiere la enmienda”.

65. *Queda aprobado el anexo II, relativo a ejemplos de formularios de inscripción, en su forma enmendada.*

66. El **Presidente** pregunta si se ha llegado a un acuerdo en el grupo de consulta oficioso sobre la forma de aclarar, en todo el proyecto de guía sobre el registro, el significado de las palabras “otorgante” y “acreedor garantizado”.

67. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que las delegaciones de Alemania y los Estados Unidos han hecho circular una propuesta en inglés a todas las delegaciones.

68. La **Sra. Sabo** (Canadá) propone que se aplace el debate sobre la propuesta hasta que se disponga de una versión en todos los idiomas de trabajo.

69. *Así queda acordado.*

70. El **Presidente** señala a la atención de la Comisión el documento A/CN.9/XLVI/CRP.4, que contiene el proyecto de decisión relativo a la aprobación de la *Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales*.

71. *Queda adoptada la decisión relativa a la aprobación de la Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales.*

Se levanta la sesión a las 17.00 horas.

**Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación
de un registro de garantías reales (continuación)**

**Acta resumida de la 970ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
Viena, el martes 16 de julio de 2013, a las 9.30 horas**

[A/CN.9/SR.970]

Presidente: Sr. Labardini Flores (Vicepresidente) (México)

Se declara abierta la sesión a las 9.55 horas.

Examen de cuestiones relacionadas con las garantías reales

a) Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación de un registro de garantías reales (continuación)
(A/CN.9/WG.VI/ WP.54 y Add.1 a 4; A/CN.9/781 y Add.1 y 2; A/CN.9/764 y 767; A/CN.9/XLVI/CRP.6)

1. El **Presidente** invita a la Comisión a examinar la propuesta relativa a la terminología utilizada en la Guía Legislativa sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales (el proyecto de guía sobre el registro) presentada por las delegaciones de Alemania y los Estados Unidos de América que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.6.

2. El **Sr. Cohen** (Estados Unidos de América) dice que la propuesta centra la atención en las definiciones de los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” que figuran en la sección sobre terminología del documento A/CN.9/781/Add.1. La Comisión ha observado que la forma en que se han utilizado esos términos en el proyecto de guía sobre el registro a veces corresponde a esas definiciones pero en otros casos refleja la definición contenida en la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas* (la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*). Se ha sugerido que conviene alertar a los lectores respecto de este problema mediante una aclaración en el sentido de que esos términos pueden tener cualquiera de esos dos significados según el contexto. Otra sugerencia es que se brinde orientación a los lectores mediante la inclusión de dos conjuntos de definiciones. En el caso de la expresión “acreedor garantizado”, por ejemplo, una definición se referiría a la persona a la que se otorga la garantía y una segunda definición se referiría a la persona designada en la notificación como el acreedor garantizado. La propuesta de Alemania y los Estados Unidos es una solución de avenencia entre esas dos sugerencias. Si bien se supone que los lectores adoptarían una decisión acertada respecto del término “otorgante” puesto que el significado

previsto de esta palabra suele entenderse sin mayor dificultad en función del contexto, no sucede lo mismo con la expresión “acreedor garantizado”.

3. A raíz de las consultas oficiosas celebradas antes de la reunión se llegó al acuerdo de adoptar un enfoque más sencillo con respecto a la aplicación de la propuesta. Ahora se propone suprimir, en el proyecto de guía sobre el registro, las definiciones de “otorgante” y “acreedor garantizado” de modo que cuando estos términos se utilicen en el proyecto de guía reflejen las definiciones que figuran en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. En las recomendaciones 3, apartado g), 18, 19 y 31, la expresión “acreedor garantizado” se sustituiría por “la persona designada en la notificación como el acreedor garantizado”. Por último, se incluiría un texto en el comentario que sigue a la sección sobre terminología en el que se indique que los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” se utilizan en el comentario conforme a la definición que figura en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, pero que podrían darse casos en que, a la luz de su contexto, tienen un significado más limitado.

4. El **Sr. Boettcher** (Alemania) dice que el plan inicial de definir los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” resultaba demasiado complicado. A su juicio, las nuevas propuestas de redacción presentadas por el representante de los Estados Unidos constituyen una solución viable.

5. La **Sra. Walsh** (Canadá) también acoge con beneplácito las propuestas, que considera una solución no demasiado complicada.

6. Propone que en la recomendación 18, apartado b), el término “otorgante” se sustituya por “la persona designada en la notificación como el otorgante”.

7. El **Sr. Tosato** (Italia), el **Sr. Maradiaga** (Honduras) y la **Sra. Talero** (Colombia) apoyan la propuesta de los representantes de Alemania y los Estados Unidos.

8. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) pregunta si la versión revisada del término “acreedor garantizado” debería utilizarse en las recomendaciones 30, 32 y 33, además de en la recomendación 31. En las recomendaciones 30 y 32 no se menciona concretamente al acreedor garantizado pero el comentario contiene una extensa explicación con respecto a las enmiendas y cancelaciones realizadas por los acreedores garantizados. El orador pregunta asimismo si en el comentario debería hacerse referencia a la definición que figura en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* o a “la persona designada en la notificación como el acreedor garantizado”.

9. El **Sr. Cohen** (Estados Unidos de América) dice que la política fundamental está expresada en la recomendación 19, relativa a la enmienda de la información consignada en el fichero del registro accesible al público. Según la modificación propuesta por las delegaciones de Alemania y los Estados Unidos, esa recomendación haría referencia a una enmienda por “la persona designada en la notificación como el acreedor garantizado”. Una política análoga se aplica a la recomendación 31, relativa a la enmienda global de la información relativa a un acreedor garantizado consignada en múltiples notificaciones. Si en el comentario sobre las recomendaciones 30 y 32 se menciona a un acreedor garantizado, la referencia sería supuestamente a la persona con derecho a hacer una enmienda y, por consiguiente, a “la persona designada en la notificación como el acreedor garantizado”. No es necesario modificar la recomendación 33 puesto que en ella se enumeran las obligaciones del acreedor garantizado con respecto, en particular, al otorgante. El acreedor garantizado no debería poder eximirse de esas obligaciones simplemente designando a otra persona en la notificación.

10. El **Sr. Tosato** (Italia) es partidario de la propuesta de aclarar, en el comentario, cuál de las definiciones de “acreedor garantizado” es la que se utiliza en las distintas recomendaciones.

11. La **Sra. Walsh** (Canadá) hace hincapié en que no es necesario utilizar la frase “la persona designada en la notificación como el acreedor garantizado” a lo largo del comentario. El significado debería entenderse a la luz del contexto.

12. El **Presidente** entiende que la Comisión conviene en suprimir los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” en la sección sobre terminología; sustituir la expresión “acreedor garantizado” por “la persona designada en la notificación como el acreedor garantizado” en las recomendaciones 3, apartado g), 18, 19 y 31; indicar en el comentario que si bien los términos

“otorgante” y “acreedor garantizado” se utilizan generalmente según la definición contenida en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, podrían darse casos en que, según el contexto, se refieren a la persona designada en la notificación; y reemplazar el término “otorgante” por “la persona designada en la notificación como el otorgante” en la recomendación 18, apartado b).

13. *Así queda acordado.*

14. *Queda aprobada la Guía Legislativa sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales en su forma enmendada.*

b) Informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo VI (A/CN.9/764 y 767; A/CN.9/WG.VI/WP.55 y Add.1 a 4)

15. El **Presidente** invita a la secretaria a presentar el informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo VI.

16. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que los informes sobre los períodos de sesiones 22° y 23° del Grupo de Trabajo VI figuran en los documentos A/CN.9/764 y 767. Los párrafos 63 y 64 del documento A/CN.9/767 contienen un resumen del intercambio de opiniones del Grupo de Trabajo con respecto al proyecto de Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas (el proyecto de Ley Modelo). La Comisión confió al Grupo de Trabajo la tarea de preparar una ley modelo acorde con los textos de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas y basada en las recomendaciones generales de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. La secretaria preparó, en nombre del Grupo de Trabajo, el proyecto preliminar de Ley Modelo que figura en los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.55 y Add.1 a 4, que consiste esencialmente en una sinopsis de las recomendaciones no relacionadas con bienes contenidas en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*.

17. Según la Comisión, la ley modelo debería ser sencilla, breve y concisa, teniendo en cuenta que la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas* tiene 450 páginas y contiene unas 250 recomendaciones. Al mismo tiempo, sin embargo, debería ajustarse a todos los textos elaborados por la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas. El cumplimiento de ambas condiciones no es una tarea fácil. Si en aras de la sencillez se excluyen los principales bienes comerciales, varias leyes podrían ser aplicables a lo que es básicamente la misma operación. En abril de 2013, después del 23° período de sesiones del Grupo de Trabajo, la secretaria llevó a cabo amplias consultas e investigaciones y ha comenzado a reformular del proyecto

de Ley Modelo. Si bien el nuevo proyecto contiene menos de la mitad del número de recomendaciones en comparación con la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, abarca todas las principales categorías de bienes.

18. En resumen, el Grupo de Trabajo VI ha tomado nota del mandato de la Comisión y la secretaría está preparando una versión revisada del proyecto de Ley Modelo sobre la base de las instrucciones dadas por el Grupo de Trabajo. La Comisión tiene previsto examinar las prioridades para la labor futura más adelante durante el período de sesiones, teniendo en cuenta los programas de trabajo de todos los Grupos de Trabajo. Por tanto, la Comisión tal vez desee tomar nota, en la presente reunión, del informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo VI y confirmar su decisión de preparar un proyecto de Ley Modelo, a reserva de las deliberaciones futuras sobre las prioridades generales.

19. La **Sra. Sabo** (Canadá) dice que el Grupo de Trabajo VI está actuando en la dirección correcta al preparar un proyecto de Ley Modelo que complementará la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. En su opinión, la Comisión debería dar prioridad a esa tarea.

20. El **Sr. Bellenger** (Francia) acoge favorablemente el anuncio de la secretaría sobre la preparación de una versión algo más corta del proyecto de Ley Modelo. El documento debería centrar la atención en el establecimiento de una serie de principios rectores que ayuden a los Estados que necesitan actualizar su legislación.

21. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que el proyecto de Ley Modelo será especialmente útil para los países con economías emergentes. Se han logrado considerables progresos en la promulgación de legislación sobre operaciones garantizadas, por ejemplo en América Latina, en parte gracias a la Ley Modelo Interamericana sobre Legislación de Transacciones Seguras formulada por la Organización de los Estados Americanos.

22. El orador concuerda con las observaciones de la secretaría sobre el alcance del proyecto de Ley Modelo, que debe centrarse en los bienes que son económicamente valiosos en el contexto de las operaciones garantizadas.

23. El **Sr. Dashe** (Kenya) dice que Kenya, como economía emergente, actualmente carece de legislación sobre las operaciones garantizadas. Por tanto, espera con interés la posibilidad de recibir y aplicar el proyecto de Ley Modelo.

24. La **Sra. Talero** (Colombia) dice que Colombia actualizó recientemente su legislación sobre las operaciones garantizadas con ayuda de la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. No obstante, dada la magnitud de la Guía, el acceso a una ley modelo breve y concisa será sumamente valioso.

25. El **Sr. Özsunay** (Turquía) dice que el proyecto de Ley Modelo contribuirá de forma valiosa a la armonización de la legislación nacional, del mismo modo que la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.

26. El **Presidente** dice que la Comisión ha tomado nota de los progresos realizados por el Grupo de Trabajo VI en la redacción de una Ley Modelo sobre las Operaciones Garantizadas y destaca la importancia de este proyecto para ayudar a las naciones de todo el mundo a promulgar legislación conexas. Con sujeción al resultado del debate previsto sobre las prioridades que establecerá la Comisión con respecto a su labor futura, entiende que la Comisión desea confirmar su decisión de que el Grupo de Trabajo VI prosiga su labor relativa al proyecto de Ley Modelo.

27. *Así queda acordado.*

c) Coordinación en el ámbito de las garantías reales

28. El **Presidente** invita a la secretaría a presentar el tema 5 c), relativo a la coordinación en el ámbito de las garantías reales.

29. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que una de las cuestiones que ha de examinar la Comisión en relación con el tema 5 c) es la coordinación con la Comisión Europea con respecto a la ley aplicable a los efectos de las cesiones frente a terceros. La cuestión se abordó en un proyecto del Reglamento de la Comisión Europea que establece normas uniformes para determinar la ley aplicable a las obligaciones contractuales en la Unión Europea, el cual reemplazó el Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales de 1980. El proyecto contenía un artículo en el que se aplicaba en gran medida el enfoque adoptado por la CNUDMI en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional y en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, en particular el de invocar la ley del lugar en que se encuentra el cedente. Sin embargo, el proyecto de disposición no se incluyó en el texto final. La Comisión Europea pidió al British Institute of International and Comparative Law que realizara un estudio sobre la cuestión y actualmente prepara un informe

a la luz de sus resultados. La secretaría participó en una reunión de coordinación con la Comisión Europea en Bruselas, de conformidad con el mandato de la Comisión, con miras a promover la adopción de un enfoque uniforme pero lo suficientemente flexible para poder satisfacer las necesidades de las partes en relación con todo tipo de operaciones. La Comisión tal vez desee tomar nota de los esfuerzos de coordinación de la secretaría y confirmar su mandato a fin de lograr un acuerdo con respecto a un enfoque uniforme de la ley aplicable a los efectos de las cesiones frente a terceros. A fines de 2013 o principios de 2014 podría celebrarse otra reunión con la Comisión Europea, en la cual se examinaría un proyecto de informe de la Comisión Europea. En el informe se analizarían las cuestiones pertinentes pero no era probable que se adoptara una posición al respecto antes de las elecciones al Parlamento Europeo previstas en junio de 2014.

30. Una segunda cuestión que ha de examinarse es la coordinación con el Banco Mundial. En 2011, la CNUDMI y el Banco Mundial prepararon conjuntamente una serie de principios relativos a los derechos de los acreedores y la insolvencia. Está en curso un esfuerzo similar para la preparación de un conjunto de principios comunes sobre las operaciones garantizadas o los derechos de los acreedores garantizados, que incluirá las recomendaciones contenidas en la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*. Actualmente se está debatiendo un anteproyecto. Una vez que se disponga de un texto más avanzado, podría organizarse una reunión de expertos a fin de examinarlo en detalle. Por supuesto, la Comisión tendrá la oportunidad de examinar el texto más adelante. Entre

tanto, la Comisión tal vez desee confirmar el mandato de la secretaría de coordinar esta cuestión con el Banco Mundial. El orador expresa su gratitud por la asistencia prestada a los Estados por el Banco Mundial, muy en particular por el Grupo del Banco Mundial en su conjunto, en la esfera de las operaciones garantizadas, que en gran medida está en consonancia con las recomendaciones de la CNUDMI.

31. La **Sra. Sabo** (Canadá), el **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) y el **Sr. Boettcher** (Alemania) dan las gracias a la secretaría por su notable labor y expresan su enérgico apoyo a la continuación de su mandato de mantener la coordinación con la Comisión Europea y el Banco Mundial.

32. El **Sr. Tata** (Banco Mundial) agradece a la Comisión su excelente labor en el ámbito de las operaciones garantizadas, que es de gran utilidad para el Banco Mundial y el Grupo del Banco Mundial. Agradece asimismo a la secretaría sus esfuerzos por integrar los resultados de la labor que realiza la Comisión en esa esfera en la orientación que brinda el Banco Mundial a sus Estados miembros.

33. **El Presidente** entiende que la Comisión desea confirmar el mandato de la secretaría y alentarla a proseguir su labor de coordinación con constante entusiasmo.

34. *Así queda acordado.*

Se levanta la sesión a las 11.10 horas.

**Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación
de un registro de garantías reales (continuación)**

**Acta resumida de la 971ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
Viena, el martes 16 de julio de 2013, a las 14.00 horas**

[A/CN.9/SR.971]

Presidente: Sr. Labardini Flores (Vicepresidente) (México)

Se declara abierta la sesión a las 14.10 horas.

Examen de cuestiones relacionadas con las garantías reales

- a) **Finalización y aprobación de la Guía legislativa técnica para la creación de un registro de garantías reales (continuación)**
- b) **Informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo VI (continuación)**
- c) **Coordinación en el ámbito de las garantías reales (continuación)** (A/CN.9/WG.VI/WP.54 y Add.1 a 4; A/CN.9/WG.VI/WP.55 y Add.1 a 4; A/CN.9/764, 767, 781 y Add.1 y 2; A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.5 a 7 y 16)

1. El **Presidente** invita a la secretaría a presentar la sección del proyecto de informe sobre la finalización y aprobación de la Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales.

2. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que la primera parte del proyecto de informe figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.5. La segunda parte figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.6, que se distribuirá en breve. En el acta resumida se presentará y reflejará un informe oral sobre las deliberaciones de la sesión anterior.

3. El **Presidente** invita a la Comisión a hacer observaciones sobre el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.5.

4. El **Sr. Weise** (American Bar Association) observa que en los párrafos 6 y 9 se utilizan los términos “otorgante” y “acreedor garantizado”, sobre los cuales se adoptaron varias decisiones en la sesión anterior. Pregunta si debería insertarse una nota a pie de página a fin de remitir a esas decisiones.

5. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que los párrafos 6 y 9 pueden suprimirse. Como alternativa, puede reemplazarse la frase “la Comisión estuvo de acuerdo en” por “la Comisión examinó una propuesta de” y puede

insertarse una remisión a la parte posterior del informe en que se reflejan las decisiones de la Comisión.

6. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) y el **Sr. Boettcher** (Alemania) expresan su preferencia por la segunda opción, dado que es útil conservar el historial de redacción.

7. *Así queda acordado.*

8. El **Sr. Dubovec** (Centro Jurídico Nacional para el Libre Comercio Interamericano), refiriéndose a la frase del párrafo 12 en la que se afirma que solo sería necesario coordinar las inscripciones registrales si el régimen de las operaciones garantizadas “excluía” determinados tipos de activos. Al respecto, su organización ha señalado que la coordinación solo sería necesaria si el régimen de las operaciones garantizadas “incluía” esos activos debido a que solo en esas circunstancias es que se requiere la coordinación entre regímenes distintos. En consecuencia, propone que se reemplace la palabra “excluía” por “incluía”.

9. *Así queda acordado.*

10. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) propone que se modifique el párrafo 15, apartado c) para que diga: “La recomendación 8, apartado a), debía revisarse de modo que hiciera referencia a ‘información’ no incorporada en ‘cada espacio previsto’”.

11. *Así queda acordado.*

12. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) sugiere que se suprima la última oración del párrafo 19, en la que la Comisión pospone la adopción de una decisión sobre la recomendación 13 hasta más avanzado el periodo de sesiones y se reemplace por el párrafo del documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.6 en el que se consigna la decisión correspondiente.

13. *Así queda acordado.*

14. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que se insertará un nuevo párrafo después del párrafo 25 a fin de reflejar las decisiones de la Comisión con respecto a los términos

“otorgante” y “acreedor garantizado”. El párrafo 25 hace referencia a las recomendaciones 23 a 27, lo que es correcto a la luz del historial de redacción. Sin embargo, tal vez sería preferible hacer referencia a “ciertas recomendaciones” dado que los números de estas han cambiado.

15. El **Sr. Weise** (American Bar Association) apoya la enmienda propuesta por la secretaría.

16. *Así queda acordado.*

17. *Queda aprobada la sección del proyecto de informe contenida en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.5 en su forma enmendada.*

18. El **Presidente** invita a la secretaría a presentar un informe oral sobre el resultado de la sesión anterior.

19. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que el informe que va a presentar figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.7, que se distribuirá en el curso del día.

20. Durante la primera parte de la sesión, la Comisión examinó los términos “otorgante” y “acreedor garantizado” que figuran en el proyecto de guía sobre el registro. Lee el párrafo que refleja el debate conexo, el cual se insertará después del párrafo 25 del documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.5.

21. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que, según el apartado e), en el comentario sobre las recomendaciones 19, 30 y 32 se debería aclarar que la persona identificada en la notificación como el acreedor garantizado sería la persona autorizada para modificar la información consignada en una notificación inscrita. Dado que esto ya se ha aclarado en la recomendación 19, la aclaración en el comentario solo sería necesaria en el caso de las recomendaciones 30 y 32. El orador propone que se modifique el texto para que diga que en el comentario se debería aclarar la cuestión “cuando proceda”.

22. La **Sra. Walsh** (Canadá) dice que, a juicio de su delegación, no es necesaria la aclaración, especialmente en lo que respecta a las recomendaciones 30 y 32, que no contienen referencia alguna al acreedor garantizado. La Comisión no debe dar la impresión de que le compete decidir quién debería estar autorizado a hacer una enmienda o una cancelación. Sería preferible incluir una oración general en el comentario en el sentido de que la expresión “acreedor garantizado” significa ya sea la persona que recibe la garantía real o la persona designada en la notificación como el acreedor garantizado, según el contexto. Por consiguiente, propone que se suprima el apartado e).

23. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) entiende que en el comentario se haría simplemente referencia a la norma establecida en la recomendación 19 sobre la persona autorizada a hacer una enmienda. Conforme al apartado c), la recomendación 19 se referiría a la persona designada como acreedor garantizado en la notificación.

24. La **Sra. Walsh** (Canadá) señala que las recomendaciones 30 y 32 no se refieren a la persona autorizada a hacer una enmienda.

25. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que el contenido del apartado e) es la consecuencia lógica de la decisión reflejada en el apartado c) de sustituir la expresión “acreedor garantizado”, que figura en la recomendación 3, apartado g), y en las recomendaciones 18, 19 y 31, por la frase “la persona identificada en la notificación como el acreedor garantizado”. Si bien las recomendaciones 30 y 32 no contienen la expresión “acreedor garantizado”, guardan relación con las enmiendas y cancelaciones. Por tanto, es necesario que el comentario se refiera, cuando proceda, al acreedor garantizado como la persona autorizada a hacer las enmiendas y cancelaciones.

26. La **Sra. Sabo** (Canadá) reitera la opinión de su delegación de que sería suficiente incluir una explicación general en la sección sobre terminología con respecto a los significados contextuales de la expresión “acreedor garantizado” y que las instrucciones incluidas en el proyecto de informe sobre las diversas enmiendas al comentario son innecesarias.

27. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que el comentario sobre las recomendaciones 30 y 32 requeriría una remisión a la expresión “acreedor garantizado” en el contexto en que figura en la recomendación 19 con el fin de aclarar esta cuestión para el lector.

28. La **Sra. Walsh** (Canadá) dice que las recomendaciones 30 y 32 no se refieren a las obligaciones del acreedor garantizado. Simplemente indican el tipo de información que se requiere en una notificación de enmienda o de cancelación.

29. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que, a su juicio, el apartado e) refleja la decisión adoptada en la sesión anterior. Sin embargo, si puede causar confusión, su delegación está dispuesta a aceptar los argumentos presentados por las representantes del Canadá.

30. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) sugiere que se supriman las referencias a las recomendaciones 30 y 32 en el apartado e). Señala, no obstante, que el comentario sobre las recomendaciones 30 y 32 que figura en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.4 contiene varias referencias

al acreedor garantizado. En la sección sobre terminología podría incluirse una remisión al comentario la primera vez que se utilice esa expresión.

31. El **Presidente** entiende que la Comisión desea suprimir las referencias a las recomendaciones 30 y 32 en el apartado e) y, cuando proceda, hacer referencia al comentario que figura a continuación de los párrafos pertinentes de la sección sobre terminología.

32. *Así queda acordado.*

33. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) lee la sección titulada “Informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo VI y labor futura” del documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.7, que se distribuirá más tarde en el curso del día.

34. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) propone que se sustituyan las palabras “Se opinó en general” por “Se opinó unánimemente”.

35. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) sugiere que se sustituya la frase “Se opinó en general” por “Se acordó”.

36. *Así queda acordado.*

37. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) propone que se añada una oración en el sentido de que en el ámbito del proyecto de ley modelo se deberían incluir todos los bienes de valor económico.

38. La **Sra. Sabo** (Canadá) dice que su delegación no puede apoyar esta última propuesta dado que esta cuestión requiere un debate más a fondo.

39. El **Sr. Tosato** (Italia) dice que en la sesión anterior no se debatió la pertinencia económica de los bienes que ha de abarcar el proyecto de ley modelo. Se acordó que el proyecto de ley modelo fuera sencillo, breve y conciso y se centrara en los bienes comerciales básicos.

40. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) sugiere que la oración adicional propuesta por el representante de los Estados Unidos puede reflejarse en el proyecto de informe como una opinión que expresa un punto de vista particular. La oración podría decir lo siguiente: “Se señaló que en el ámbito de aplicación del proyecto de ley modelo deberían incluirse todos los bienes de valor económico”.

41. La última oración de la introducción general contenida en el primer párrafo podría ampliarse para explicar que la secretaría está preparando una versión revisada del proyecto de ley modelo que daría aplicación al mandato dado por la Comisión al Grupo de Trabajo y abarcaría los bienes comerciales básicos. La secretaría señaló en la sesión anterior que si se excluían los bienes

comerciales básicos, distintos regímenes podrían ser aplicables a las mismas operaciones.

42. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que la breve referencia a “bienes comerciales básicos” puede interpretarse como un mandato muy limitado o un mandato muy amplio. Sería útil proporcionar un ejemplo de lo que denota ese término.

43. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que después de “bienes comerciales básicos” tal vez podría insertarse la siguiente frase: “como equipo, inventario, créditos por cobrar, cuentas bancarias, instrumentos negociables y documentos negociables”. Si se da un ejemplo específico podría crearse cierto desequilibrio en el texto.

44. La **Sra. Rojas** (México) apoya la propuesta del representante de los Estados Unidos en el sentido de añadir una oración a fin de indicar que en el ámbito de aplicación del proyecto de ley modelo deberían incluirse todos los bienes de valor económico.

45. La **Sra. Sabo** (Canadá) dice que lo que preocupa a su delegación es que el proyecto de informe pueda prejuzgar el resultado de las deliberaciones que se celebrarán en el Grupo de Trabajo VI. Su delegación se opone a la inclusión de ejemplos después de la frase “bienes comerciales básicos”.

46. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que la utilización de la palabra “básicos” podría influir en el resultado de las deliberaciones. Algunos pueden entender que denota una amplia gama de bienes; otros, en cambio, pueden interpretarla en un sentido totalmente opuesto. Por consiguiente, propone que se sustituya por “bienes de valor económico” o bien que se incluya un ejemplo que ilustre su significado.

47. El **Sr. Tosato** (Italia) dice que “bienes comerciales básicos” es la expresión que suele emplear el Grupo de Trabajo VI y debería utilizarse también en el informe a fin de excluir todo debate sobre el ámbito de aplicación del proyecto de ley modelo, cuestión que no figura en el programa. La incorporación de nueva terminología como “bienes de valor económico” en el informe daría la impresión de que se ha realizado un debate sobre el ámbito de aplicación.

48. El **Sr. Boettcher** (Alemania) está de acuerdo con el orador anterior. El informe debería reflejar exactamente los debates celebrados en la Comisión y la inclusión de ejemplos puede prejuzgar las deliberaciones futuras sobre el ámbito de aplicación del proyecto de ley modelo.

49. El **Sr. Bellenger** (Francia) hace suyos los argumentos presentados por los representantes de Italia y Alemania.

50. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que la Comisión tiene derecho a ampliar el ámbito del mandato y la inclusión de un ejemplo indicaría los tipos de bienes que han de abarcarse. Su delegación propuso en la sesión anterior que el proyecto de ley modelo se centrara en los bienes de valor económico. El informe debería recoger esa propuesta.

51. El **Presidente** dice que hay consenso con respecto a que el informe no prejuzgue las deliberaciones futuras sobre el ámbito de aplicación del proyecto de ley modelo. Sin embargo, puede reflejar afirmaciones que presentan opiniones independientes.

52. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) reitera su sugerencia de insertar la siguiente oración al final del segundo párrafo: “Se señaló asimismo que el ámbito de aplicación del proyecto de ley modelo debería ser amplio y abarcar todos los bienes de valor económico”.

53. Al final de la última oración del primer párrafo, que se refiere a la preparación por la secretaría de una versión revisada del proyecto de ley modelo, puede añadirse el texto siguiente: “que daría aplicación al mandato que la Comisión había confiado al Grupo de Trabajo y facilitaría las operaciones de financiación comercial”. Esta es una afirmación de carácter general que no puede interpretarse como un comentario sobre el ámbito de aplicación del proyecto.

54. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que su delegación puede apoyar la nueva oración propuesta para el segundo párrafo si se suprimen las palabras “ser amplio y”. Apoya asimismo la enmienda al primer párrafo.

55. *Queda aprobada la sección del proyecto de informe relativa al informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo VI y labor futura” en su forma enmendada.*

56. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) lee dos párrafos del proyecto de informe relativos a la coordinación en el ámbito de las garantías reales. Estos párrafos se publicarán más adelante en la sección del proyecto de informe general de la Comisión sobre coordinación y cooperación (A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.16).

57. *Queda aprobada la sección del proyecto de informe sobre coordinación en el ámbito de las garantías reales.*

Se suspende la sesión a las 15.45 horas y se reanuda a las 16.10 horas.

58. El **Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.6.

59. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América), refiriéndose al párrafo 11, en el que se afirma que la Comisión aprobó el capítulo V, relativo a la inscripción de notificaciones de enmienda y de cancelación, señala que en una etapa posterior del debate se hicieron enmiendas a ese capítulo. Propone que se incluya una referencia cruzada a fin de alertar a los lectores al respecto.

60. El **Sr. Bazinas** (Secretaría) dice que, como se señaló anteriormente, después del párrafo 25 del documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.5 se insertará un párrafo sobre el resultado final de las deliberaciones. Puede incluirse una remisión a ese párrafo en el párrafo 11 del documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.6.

61. El orador señala asimismo que la frase introductoria del párrafo 21 de este último documento se modificará para que diga: “En su 970ª sesión, celebrada el 16 de julio de 2013, la Comisión adoptó la siguiente decisión:”.

62. *Queda aprobado el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.6 en su forma enmendada.*

63. *Queda aprobado el proyecto de informe en su totalidad en su forma enmendada.*

Se levanta la sesión a las 16.25 horas.

Finalización y aprobación de las modificaciones de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza

Finalización y aprobación de las recomendaciones legislativas sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia

Finalización y aprobación de las modificaciones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: La Perspectiva Judicial

Acta resumida de la 973ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena, Viena, el jueves 18 de julio de 2013, a las 9.30 horas

[A/CN.9/SR.973]

Presidente: Sr. Schöll (Suiza)

Se declara abierta la sesión a las 9.35 horas.

Examen de cuestiones relacionadas con el régimen de la insolvencia:

a) Finalización y aprobación de las modificaciones de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza (A/CN.9/766; A/CN.9/792 y Add.1 a 3; A/CN.9/WG.V/WP.112; A/CN.9/XLVI/CRP.5)

1. **El Presidente** invita a la secretaría a presentar las modificaciones propuestas de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo sobre la Insolvencia Transfronteriza (la Guía para la incorporación al derecho interno).

2. La **Sra. Clift** (Secretaría) dice que las modificaciones propuestas contenidas en el documento A/CN.9/WG.V/WP.112 han sido modificadas por las decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo en su último período de sesiones, que se consignan en el documento A/CN.9/766. Si bien las modificaciones se refieren principalmente al centro de los principales intereses (CPI), también se han hecho enmiendas a la sección de las definiciones conforme al artículo 2 de la Guía para la incorporación al derecho interno. Se ha revisado asimismo la introducción de la Guía. La secretaría ha tomado nota de que los párrafos 14 a 17 se omitieron inadvertidamente en la introducción existente. La secretaría sugiere que se reintegren en el texto bajo el encabezamiento “Origen de la Ley Modelo”.

3. **El Presidente** invita a la Comisión a hacer observaciones sobre las modificaciones propuestas de la Guía para la incorporación al derecho interno contenidas en los documentos A/CN.9/766 y A/CN.9/WG.V/WP.112.

4. La **Sra. Clift** (Secretaría), refiriéndose a los párrafos 123F y 123G del documento A/CN.9/WG.V/WP.112, en relación con los factores pertinentes para determinar el centro de los principales intereses para arreglo al artículo 16, sugiere que se incluya una remisión en esos párrafos al artículo 17, en el que se aborda la cuestión del momento en que han de tenerse en cuenta esos factores.

5. La **Sra. Sabo** (Canadá), el **Sr. Beale** (Reino Unido), el **Sr. Maradiaga** (Honduras) y el **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) apoyan la sugerencia de la secretaría.

6. *Así queda acordado.*

7. La **Sra. Clift** (Secretaría) sugiere que las palabras “La Ley Modelo dispone expresamente que”, al comienzo del párrafo 166 del documento A/CN.9/WG.V/WP.112, se sustituyan por “El artículo 23, párrafo 1, dispone expresamente que”.

8. *Así queda acordado.*

9. El **Sr. Bellenger** (Francia) propone que se sustituyan las palabras “est habilité” (“goce de legitimidad”) en el párrafo 98 de la versión francesa del documento A/CN.9/WG.V/WP.112 por “détient une habilitation”.

10. *Así queda acordado.*

11. **El Presidente** señala a la atención de la Comisión el documento A/CN.9/XLVI/CRP.5, que contiene el proyecto de decisión de la Comisión sobre las modificaciones de la Guía para la incorporación al derecho interno.

12. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) dice que muchas cuestiones relativas al centro de los principales intereses se han aclarado gracias a las modificaciones de la Guía para la incorporación al derecho interno, que por

tanto será sin duda sumamente valiosa, sobre todo en el contexto de la actual crisis financiera. Apoya enérgicamente la decisión y felicita al Grupo de Trabajo y a la secretaria por la excelente labor realizada.

13. **El Presidente** hace suyo el elogio al Grupo de Trabajo y la secretaria expresado por el orador anterior.

14. *Queda aprobada la decisión relativa a las modificaciones propuestas de la Guía para la incorporación al derecho interno contenidas en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.5.*

b) Finalización y aprobación de las recomendaciones legislativas sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia (A/CN.9/766; A/CN.9/792 y Add.1 a 3; A/CN.9/WG.V/WP.113; A/CN.9/XLVI/CRP.5)

15. **El Presidente** invita a la secretaria a presentar el texto propuesto sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia.

16. La **Sra. Clift** (Secretaría) dice que el texto propuesto contenido en el documento A/CN.9/WG.V/WP.113 se ha modificado a la luz de las decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo en su último período de sesiones que figuran en el documento A/CN.9/766. Las observaciones formuladas por los gobiernos y las organizaciones internacionales están contenidas en los documentos A/CN.9/792 y Add.1 a 3 y el proyecto de decisión sobre el texto propuesto figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.5.

17. El texto propuesto crea obligaciones a las empresas en el período cercano a la insolvencia. Sin embargo, esas obligaciones solo tienen efecto una vez que se entabla un procedimiento de insolvencia. De conformidad con el mandato de la Comisión, el texto centra la atención en las disposiciones que podrían incluirse en un régimen de la insolvencia, por oposición al derecho de sociedades o al derecho penal.

18. **El Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre las recomendaciones contenidas en los documentos A/CN.9/766 y A/CN.9/WG.V/WP.113.

19. La **Sra. Clift** (Secretaría) dice que la Federación de Rusia pidió que se aclarara la expresión “gastos de administración” en la recomendación 10. La secretaria propone que se inserte una nota a pie de página que remita a los lectores a la parte pertinente del glosario que figura en la introducción de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia.

20. *Así queda acordado.*

21. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América), refiriéndose a la recomendación 12, dice que la posición de su delegación es que no es apropiado disponer medidas contra los directores además de las previstas en la esfera de la insolvencia. Esta posición se debatió ampliamente en el Grupo de Trabajo.

22. El **Sr. Baer** (Asociación Internacional de Abogados) hace suya la observación formulada por el representante de los Estados Unidos. Su Asociación sostiene sistemáticamente que no es apropiado ir más allá del ámbito de la insolvencia y prever sanciones complementarias.

23. El **Sr. Beale** (Reino Unido) dice que su delegación no tiene ningún inconveniente con respecto al texto en su forma actual. La inhabilitación de los directores por su conducta durante el período cercano a la insolvencia es un principio importante del régimen en el Reino Unido y en muchas otras jurisdicciones. La Unión Europea ha entablado negociaciones sobre el intercambio de información relativa a la insolvencia y está examinando una propuesta relativa al intercambio de información sobre la inhabilitación entre los Estados miembros de la Unión Europea.

24. La **Sra. Clift** (Secretaría) dice que se ha suprimido una oración al final del párrafo 32 del documento A/CN.9/WG.V/WP.113 relativa a la renuencia de los tribunales a cuestionar a los directores en sus operaciones comerciales. En consecuencia, también deberían suprimirse las palabras “Como se señaló anteriormente,” en el párrafo 37.

25. En el párrafo 51, la oradora sugiere que se modifique la frase “Algunos regímenes reconocen en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando el representante de la insolvencia no adopta ninguna medida” para que diga: “Cuando el representante de la insolvencia no adopta ninguna medida, algunos regímenes reconocen”.

26. *Así queda acordado.*

27. **El Presidente** señala a la atención de la Comisión el documento A/CN.9/XLVI/CRP.5, que contiene el proyecto de decisión relativo al texto propuesto sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia.

28. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de decisión. Las negociaciones relativas al texto propuesto sobre las obligaciones de los directores presentaron numerosos problemas y suscitaban varias observaciones adversas, incluidas las de su delegación. Sin

embargo, el resultado es un texto muy equilibrado que refleja las opiniones de muchos Estados distintos. Felicita nuevamente al Grupo de Trabajo V y a la secretaria por su excelente labor.

29. El **Sr. Beale** (Reino Unido) concuerda con el representante de los Estados Unidos en que la formulación del texto que la Comisión tiene ante sí fue un proyecto difícil. Elogia a la secretaria por su hábil manejo de las variadas y diferentes observaciones de las delegaciones y por la redacción de un texto que logró el consenso. La confianza en las empresas es una cuestión altamente pertinente en las circunstancias actuales, por lo que los encargados de formular las políticas en todas partes del mundo considerarán muy útil este texto.

30. *Queda aprobada la decisión relativa a las recomendaciones legislativas sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia contenidas en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.5.*

c) Finalización y aprobación de las modificaciones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: La Perspectiva Judicial (A/CN.9/766 y 778)

31. El **Presidente** invita a la secretaria a presentar los documentos relativos a las modificaciones de La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: La Perspectiva Judicial.

32. La **Sra. Clift** (Secretaría) dice que las modificaciones figuran en el documento A/CN.9/778. Cuando la Comisión aprobó el texto de la Ley Modelo en 2011, pidió a la secretaria que estableciera un mecanismo para la actualización permanente de La Perspectiva Judicial, velando por mantener el enfoque neutro. La secretaria invitó a un grupo de expertos del Canadá, Colombia, Eslovenia, los Estados Unidos, Francia, Nueva Zelandia, el Reino Unido y la República de Corea a que entablaran consultas sobre las modificaciones. Por lo general, los expertos se comunicaron por medios electrónicos y las modificaciones contenidas en el documento A/CN.9/778 son el resultado de esas comunicaciones. Se añadió un número considerable de casos y se suprimió una parte de la jurisprudencia más antigua. Se añadió al documento un anexo con una lista de los casos. Además, se actualizó La Perspectiva Judicial a fin de tener en cuenta las modificaciones de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza, y más adelante se añadirán varias referencias cruzadas.

33. La oradora propone que se incluya una referencia a los miembros de la Junta de Expertos en el último párrafo del prefacio.

34. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) apoya las modificaciones propuestas. En su opinión, deberían ponerse de relieve las referencias a las modificaciones sustantivas a la Guía para la incorporación al derecho interno pues muchas jurisdicciones interpretan actualmente la Ley Modelo basándose en una versión anterior.

35. La **Sra. Clift** (Secretaría) dice que la secretaria se ha visto enfrentada, en algunos casos, a diferencias entre la posición del Grupo de Trabajo y la Comisión, por un lado, y de una parte de la jurisprudencia existente, por otro. La secretaria decidió adoptar un enfoque histórico respecto de esta cuestión manteniendo la secuencia de los casos y señalando las leves diferencias entre la Guía para la incorporación al derecho interno y la jurisprudencia.

36. Se han adoptado varias decisiones muy importantes desde que se finalizó la última versión de La Perspectiva Judicial. Esas decisiones pueden reflejarse mediante la adición de texto o notas a pie de página, o bien en la próxima revisión.

37. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) dice que el texto puede mantenerse sin modificaciones pero debería destacarse el hecho de que la jurisprudencia no refleja las decisiones adoptadas después de cierta fecha.

38. *Queda aprobada la decisión de que el prefacio incluya una referencia a los nombres y Estados de los expertos que integran la Junta de Expertos consultados con respecto a las actualizaciones de La Perspectiva Judicial.*

39. *Queda aprobada asimismo la decisión de que en el prefacio se aclare que están incluidos los fallos anteriores al 15 de abril de 2013 y de que los fallos posteriores se tengan en cuenta en una actualización posterior de La Perspectiva Judicial con miras a su posible inclusión.*

40. Alternativamente, las palabras “Así queda acordado” pueden añadirse al final del párrafo 33. Asimismo, al final del párrafo 37 puede añadirse el texto siguiente: “Esa fecha podría ser el 15 de abril de 2013. La inclusión de fallos emitidos con posterioridad puede ser considerada en una actualización ulterior de La Perspectiva Judicial. Así queda acordado.”

41. El **Presidente** entiende que la Comisión desea tomar nota de las modificaciones de La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: La Perspectiva Judicial.

42. *Así queda acordado.*

Se suspende la sesión a las 10.35 horas y se reanuda a las 11.05 horas.

d) Informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo V (A/CN.9/763, 766 y 789)

43. **El Presidente** invita a la Comisión a participar en un intercambio preliminar de opiniones sobre la posible labor futura en relación con el régimen de la insolvencia. No se adoptarán decisiones hasta que la Comisión examine el tema 16, relativo a la labor prevista y posible labor futura, en una etapa ulterior del período de sesiones.

44. La **Sra. Clift** (Secretaría) dice que los dos textos aprobados en la presente reunión se refieren a la insolvencia de deudores o empresas. Las dos primeras partes de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia centran la atención en la insolvencia de personas o empresas deudoras. La tercera parte trata de los grupos de sociedades en situaciones de insolvencia, primero en el contexto interno y luego en un contexto transfronterizo. Al revisar la Guía para la incorporación al derecho interno, el Grupo de Trabajo decidió tratar en primer lugar el centro de los principales intereses en el contexto de los deudores individuales. Posteriormente pidió a la Comisión que confirmara su opinión de que el alcance del mandato relativo al centro de los principales intereses incluía esta cuestión en el contexto de los grupos de sociedades. El Grupo decidió asimismo examinar esa cuestión, que figura entre las más complejas en el ámbito de la insolvencia transfronteriza, en cuanto finalizara su labor relativa a la Guía para la incorporación al derecho interno. El Grupo de Trabajo también acordó que, una vez terminado su examen de las obligaciones de los directores de empresas individuales, abordaría las obligaciones de los directores en el contexto de los grupos de sociedades. En su 43º período de sesiones, celebrado en abril de 2013, el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión (documento A/CN.9/766, párrafos 104 a 109) de que todavía no había cumplido plenamente su mandato recibido en 2010. Sin embargo, el procedimiento que ha de adoptar con respecto a las cuestiones pendientes no está claro aún. Respondiendo a una propuesta de coloquio, el Grupo de Trabajo convino en que ese proyecto podía ser útil pero no debería reemplazar las sesiones del Grupo de Trabajo que fuesen necesarias para terminar de cumplir su mandato.

45. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos presentaron una propuesta relativa a la labor futura de la Comisión, contenida en el documento A/CN.9/789. En la sección relativa a la insolvencia se propone organizar un coloquio para determinar proyectos

concretos y posibles esferas de la labor futura en lugar de reuniones intergubernamentales plenas sobre la insolvencia durante el año próximo. La labor sobre la insolvencia puede reanudarse una vez que la Comisión haya determinado y aprobado un proyecto concreto adecuado. Aunque el mandato del Grupo de Trabajo no se ha agotado desde el punto de vista técnico, por el momento no se ha elaborado un plan de trabajo específico sobre las cuestiones jurídicas pendientes. Por tanto, el Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que la celebración de un coloquio puede ser útil para determinar cuáles serían los proyectos futuros más valiosos. Los Estados Unidos están de acuerdo con esa conclusión. Además, instan a la CNUDMI a que considere otros proyectos en los que se pueda aprovechar la pericia de los delegados y observadores que han participado en proyectos anteriores. Sin embargo, en vista de la incertidumbre reinante sobre los proyectos concretos más apropiados para la labor inmediata, los Estados Unidos no creen que las reuniones del grupo de trabajo vayan a constituir una utilización prudente de recursos cada vez más escasos mientras se concretan esos proyectos.

46. **El Presidente** dice que la opinión predominante en el Grupo de Trabajo es que un coloquio puede ser útil pero la idea de que reemplace las sesiones del Grupo de Trabajo no ha obtenido suficiente apoyo.

47. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) conviene en que la opinión predominante en el Grupo de Trabajo es que debe proseguirse la labor. No obstante, uno de los requisitos de la CNUDMI para la autorización de toda labor futura es la existencia de un plan de trabajo específico. El Grupo de Trabajo V no tiene un plan de trabajo. Si bien su delegación no se opone a que continúe la labor en la esfera del régimen de la insolvencia, opina que, dada la escasez de recursos, esa norma debería aplicarse al Grupo de Trabajo.

48. **El Presidente** dice que, a su juicio, el Grupo de Trabajo necesita reflexionar sobre la mejor forma de cumplir el resto de su mandato.

49. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que el documento A/CN.9/789 se basa en el informe del Grupo de Trabajo contenido en el documento A/CN.9/766.

50. El **Sr. Beale** (Reino Unido) dice que el mandato relativo a la finalización de la labor sobre los grupos de sociedades es sumamente importante. Se desaprovechará una oportunidad si el Grupo de Trabajo no termina su labor sobre lo que constituye un tema clave en la esfera de la insolvencia transfronteriza. Los textos que el Grupo de Trabajo ha redactado a lo largo de los años son de gran

utilidad práctica para los encargados de la formulación de políticas en todo el mundo. El orador confía en que los resultados de su labor futura sean del mismo calibre.

51. El **Presidente** pregunta a las delegaciones que estiman que las sesiones del Grupo de Trabajo deben suspenderse qué clase de señal política dará la cesación de la labor de la CNUDMI sobre la insolvencia en una situación de reciente crisis financiera.

52. Invita a las delegaciones que opinan que las sesiones del Grupo de Trabajo no deben suspenderse a que presenten una estimación del número de sesiones que serían necesarias para cumplir la totalidad del mandato, dado que la escasez de recursos es una preocupación legítima.

53. El **Sr. Bellenger** (Francia) dice que su delegación se opone al examen del centro de los principales intereses en el contexto de los grupos de sociedades, pues causaría trastornos en la legislación existente al negar la autonomía de las empresas que integran esos grupos. En consecuencia, su delegación estima que el mandato se ha cumplido a este respecto. El Grupo de Trabajo debería concentrarse más bien en temas como la coordinación de las actuaciones y la colaboración entre directores.

54. La **Sra. Fedko** (Federación de Rusia) propone un nuevo tema que es sumamente pertinente en las circunstancias actuales, a saber, la formulación de una norma en pro del bienestar de los trabajadores en el contexto de la insolvencia. No queda claro si esto puede abordarse en el marco del mandato existente.

55. Su delegación estima que el Grupo de Trabajo debería continuar sus sesiones, pero también puede respaldar la celebración de un coloquio entre períodos de sesiones.

56. La **Sra. Talero** (Colombia) hace hincapié en la importancia de celebrar un coloquio a fin de identificar posibles temas para la labor futura que puedan ayudar a los países que enfrentan dificultades derivadas de la crisis y tienen problemas para resolver los desafíos existentes en la esfera de la insolvencia. El coloquio también puede examinar la forma de cumplir la parte restante del mandato del Grupo de Trabajo.

57. La **Sra. Sabo** (Canadá) dice que su delegación apoya la propuesta de los Estados Unidos. Dada la actual escasez de recursos de la CNUDMI, es fundamental establecer prioridades claras entre sus numerosos proyectos. Si bien el Canadá reconoce la importante labor realizada por el Grupo de Trabajo V, hace hincapié en la complejidad de la cuestión relativa a los grupos de sociedades. El Grupo de

Trabajo de hecho ha reconocido que necesita tiempo para reflexionar sobre la mejor manera de continuar. El coloquio brinda una oportunidad de analizar la mejor forma de abordar la cuestión de los grupos de sociedades, generar ideas sobre la labor futura y atraer a nuevos colaboradores. Por tanto, el coloquio facilitaría, y por cierto no impediría, el cumplimiento del mandato del Grupo de Trabajo. Por otra parte, no enviaría un mensaje negativo. La propia Comisión recibe poca publicidad; en cambio, un coloquio atraería mucha más atención y proclamaría el hecho de que la CNUDMI aborda temas importantes.

58. El **Presidente** pregunta si a juicio de la delegación del Canadá no deberían programarse otras sesiones del Grupo de Trabajo por el momento.

59. La **Sra. Sabo** (Canadá) contesta afirmativamente. Supone que la Comisión volverá a convocar al Grupo de Trabajo en el otoño de 2014. En ese momento puede abordar las cuestiones pendientes en un marco de tiempo más breve.

60. El **Sr. Ghia** (Italia) apoya los argumentos presentados por el representante del Reino Unido. En Italia se inscriben diariamente unas cincuenta declaraciones de insolvencia, varias de las cuales por lo general guardan relación con empresas extranjeras. Por consiguiente, estima que la Comisión debería aprovechar la oportunidad de finalizar su labor sobre las cuestiones relativas a los grupos de sociedades. En particular, es esencial aclarar las cuestiones relacionadas con el centro de los principales intereses y las obligaciones de los directores en ese contexto. Cree que dos sesiones del Grupo de Trabajo bastarían a esos efectos.

61. La **Sra. Talero** (Colombia) apoya las opiniones expresadas por los representantes de los Estados Unidos y el Canadá.

62. El **Sr. Kono** (Japón) hace suyas las opiniones de los representantes del Reino Unido e Italia. Una orientación de alcance internacional sobre la cuestión de los grupos de sociedades sería acogida muy favorablemente.

63. El **Sr. Tata** (Banco Mundial) dice que el Banco Mundial es uno de los principales beneficiarios de la labor del Grupo de Trabajo V y de la Comisión. Las cuestiones que la crisis financiera sigue suscitando afectan a todas las jurisdicciones, en particular a los países en desarrollo. En el contexto de la globalización, una de las cuestiones más críticas y problemáticas es la del tratamiento de los grupos de sociedades. Esta es una fuente de considerable incertidumbre y confusión y las decisiones legales a ese respecto no han sido muy coherentes. En consecuencia, el

Banco Mundial estima que el Grupo de Trabajo debería abordar la cuestión de los grupos de sociedades, así como las obligaciones de los directores.

64. Refiriéndose a la evolución de los regímenes de insolvencia especializados en diversos contextos, el orador sugiere que el futuro programa de trabajo del Grupo de Trabajo incluya asimismo la interfaz entre el régimen de la insolvencia relativo al derecho de sociedades en general y los regímenes de insolvencia especializados.

65. El **Sr. Maradiaga** (Honduras) apoya las propuestas presentadas por los representantes de los Estados Unidos y el Canadá.

66. La **Sra. Kagwanja** (Kenya), recalcando la necesidad de tener en cuenta los intereses de los países en desarrollo, se suma al orador anterior en su apoyo a las propuestas de los representantes de los Estados Unidos y el Canadá.

67. El **Sr. Bellenger** (Francia) dice que su delegación no se opone a la continuación de las sesiones del Grupo de Trabajo siempre y cuando el tema fundamental del debate no sea el centro de los principales intereses en el contexto de los grupos de sociedades. Observa, en este contexto, que la Unión Europea, que actualmente está considerando posibles enmiendas al Reglamento del Consejo de Europa núm. 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia, ha decidido dejar de lado la cuestión del centro de los principales intereses y mantener la autonomía de las empresas subsidiarias. Su delegación apoya la idea de celebrar un coloquio.

68. El **Sr. Beale** (Reino Unido) dice que el centro de los principales intereses sigue siendo un concepto fundamental en el Reglamento del Consejo de Europa sobre procedimientos de insolvencia. Con respecto a los grupos de sociedades, la Unión Europea está elaborando normas para la coordinación de insolvencias múltiples dentro de un grupo de sociedades a fin de asegurar el mejor resultado posible en el marco de la legislación vigente. Cuando el Grupo de Trabajo V examinó por primera vez los grupos de sociedades, el objetivo fundamental no era lograr una nueva comprensión del centro de los principales intereses que fuese aplicable solo a esos grupos, sino analizar cómo se coordinaban los grupos de sociedades. Los esfuerzos de la Unión Europea en materia de elaboración de normas de cooperación y coordinación entre los tribunales especializados en la insolvencia de grupos de sociedades también deberían examinarse en ese contexto.

69. El **Presidente**, resumiendo el debate, dice que todas las delegaciones están de acuerdo en que la labor realizada

por el Grupo de Trabajo V ha brindado una valiosa orientación práctica sobre las cuestiones relativas a la insolvencia y contribuido a aclarar los conceptos jurídicos. Por otra parte, hay consenso con respecto a que la CNUDMI debe utilizar sus escasos recursos de forma razonable y a que es preciso examinar detenidamente la cuestión de la labor futura.

70. Es reacio a dividir a los oradores en dos campos, pues está convencido de la posibilidad de conciliar propuestas aparentemente opuestas. Por otra parte, ninguna de las delegaciones partidarias de suspender las sesiones del Grupo de Trabajo ha sugerido que también debe suspenderse la labor de la secretaría sobre los temas pertinentes. Un gran número de delegaciones opina que el mandato del Grupo de Trabajo no se ha cumplido completamente y algunas delegaciones estiman que las cuestiones pendientes pueden resolverse dentro de un período relativamente breve. El representante de Francia ha condicionado su apoyo a la continuación de las reuniones del Grupo de Trabajo en función de las cuestiones que se aborden. Un número importante de delegaciones también ha apoyado la idea de celebrar un coloquio a fin de determinar posibles direcciones para la labor futura. Todos los argumentos presentados se reflejarán en el informe y el debate continuará cuando la Comisión examine el tema 16 del programa.

71. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que en el acta debería consignarse que la mayoría de las delegaciones ha expresado apoyo a la celebración de un coloquio y, por consiguiente, a la suspensión de las sesiones del Grupo de Trabajo V.

72. El **Presidente** dice que no puede inferirse del apoyo expresado a la celebración de un coloquio que las delegaciones están a favor de suspender las sesiones del Grupo de Trabajo.

73. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que las dos cuestiones están relacionadas entre sí en la medida en que la organización de un coloquio y la celebración de las sesiones del Grupo de Trabajo se financiarían con cargo a los mismos recursos y se utilizarían los mismos servicios de conferencias. Actualmente la Comisión dispone de recursos suficientes para financiar 14 semanas de reuniones al año. Si se celebra un coloquio de tres días, el tiempo disponible para reuniones del Grupo de Trabajo u otras reuniones de la Comisión se reduciría en tres días.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.

**Acta resumida de la 975ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
Viena, el viernes 19 de julio de 2013, a las 14.00 horas**

[A/CN.9/SR.975]

Presidente: Sr. Schöll (Suiza)

Se declara abierta la sesión a las 14.20 horas.

Aprobación del proyecto de informe

(A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.4, Add.7, Add.8, Add.12 a 15 y Add.20)

1. **El Presidente** invita a que se formulen observaciones sobre la sección del proyecto de informe dedicada a la finalización y aprobación del Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado (A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.4).

2. El orador señala la propuesta de la delegación de Suiza de añadir al final del párrafo 7 la oración siguiente: “También se sugirió que sería prematuro decidir qué forma podría adoptar la labor futura en esa esfera y que cualquier decisión al respecto debería preservar la opción de analizar la cuestión de los procedimientos paralelos en los arbitrajes comerciales en el contexto de la Convención de Nueva York.”

3. *Así queda acordado.*

4. *Se aprueba la sección del proyecto de informe que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.4, en su forma enmendada.*

5. **El Presidente** invita a que se formulen observaciones sobre la sección del proyecto de informe titulada “Comercio electrónico: informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo IV” (A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.12).

6. El **Sr. Bellenger** (Francia) propone modificar las palabras “Se señaló que” al comienzo del párrafo 4 por “Se expresó el deseo de que” (*Le souhait a été émis que*). Propone asimismo que las palabras “tal vez no sería posible” a final de oración sean reemplazadas por “tal vez creara dificultades jurídicas” (*pouvait soulever des difficultés juridiques*).

7. *Así queda acordado.*

8. *Se aprueba la sección del proyecto de informe que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.12, en su forma enmendada.*

9. **El Presidente** dice que la sección del proyecto de informe sobre la finalización y aprobación de la Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.7 se aprobó con arreglo a una presentación oral. **El Presidente** invita a que se formulen observaciones sobre el informe escrito.

10. *Se aprueba la sección del proyecto de informe que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.7.*

11. **El Presidente** invita a que se formulen observaciones sobre la sección del proyecto de informe titulada “Asistencia técnica: reforma legislativa” (A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.13).

12. *Se aprueba la sección del proyecto de informe que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.13.*

13. **El Presidente** invita a que se formulen observaciones sobre la sección del proyecto de informe relativa al fomento de los modos necesarios para asegurar una interpretación y una aplicación uniformes de los textos jurídicos de la CNUDMI (A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.14).

14. *Se aprueba la sección del proyecto de informe que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.14.*

15. **El Presidente** invita a que se formulen observaciones sobre la sección del proyecto de informe dedicada a la situación y promoción de los textos de la CNUDMI (A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.15).

16. *Se aprueba la sección del proyecto de informe que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.15.*

17. **El Presidente** invita a que se formulen observaciones sobre la sección del proyecto de informe relativa a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General (A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.20).

18. *Se aprueba la sección del proyecto de informe que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.20.*

19. **El Presidente** invita a que se formulen observaciones sobre la sección del proyecto de informe relativa al examen de cuestiones relacionadas con el régimen de la insolvencia (A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.8).

20. El **Sr. Bellenger** (Francia), en referencia a la sección d), relativa al informe sobre la marcha de la labor del Grupo de Trabajo V, dice que no se ha aclarado la cuestión de si la aplicabilidad del concepto de centro de los principales intereses a los grupos de empresas forma parte del mandato del Grupo de Trabajo. Propone por lo tanto que se introduzca una frase en la segunda oración del párrafo 18 en la que se diga que el coloquio debería aclarar el mandato del Grupo de Trabajo en ese sentido.
21. **El Presidente** observa que en la primera oración de la sección d) se afirma que el Grupo de Trabajo ha examinado los demás elementos del mandato, particularmente en relación con la aplicabilidad del concepto de centro de los principales intereses a los grupos de empresas.
22. El **Sr. Beale** (Reino Unido) propone añadir al final del párrafo 18 la oración siguiente: “Se expresó también la opinión de que el Grupo de Trabajo V debía continuar con su mandato tal como estaba previsto.”
23. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) dice que el fondo de la nueva oración que propone el representante del Reino Unido queda reflejado en el párrafo 19. En la primera oración del párrafo 18 propone reemplazar las palabras “reflexionar acerca del modo de” por la palabra “aclarar”. El orador pone de relieve la importancia de mantener un equilibrio entre las distintas opiniones que se han expresado durante el examen.
24. El **Sr. Bellenger** manifiesta su apoyo a la enmienda propuesta por el representante de los Estados Unidos.
25. *Así queda acordado.*
26. El **Sr. Schoefisch** (Alemania) dice que la enmienda propuesta por el representante del Reino Unido denota apoyo a que el Grupo de Trabajo continúe cumpliendo su mandato sin necesidad de celebrar un coloquio. La oración del párrafo 19 mencionada por el representante de los Estados Unidos presupone la continuación del mandato del Grupo de Trabajo una vez celebrado el coloquio.
27. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) propone que, si en el párrafo 18 se incluye la oración sugerida por el Reino Unido, se añada la siguiente oración nueva: “También se expresó la opinión de que no se debería proseguir con el mandato, puesto que el Grupo de Trabajo no contaba con un plan para lo que emanaría de su labor relativa a esas cuestiones, y que no debería emprenderse ninguna actividad al respecto hasta que se aclarase esa cuestión.”
28. El **Sr. Beale** (Reino Unido) dice que no recuerda que la Comisión examinara el posible cese del mandato del Grupo de Trabajo. El examen se centró en la manera en que este debería concluir.
29. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) dice que su delegación trató el tema en la sesión celebrada la mañana anterior.
30. La **Sra. Nimeřická** (Observadora de la República Checa) y el **Sr. Kono** (Japón) manifiestan su apoyo a la inclusión, en el párrafo 18, de la oración propuesta por el representante del Reino Unido.
31. La **Sra. Sabo** (Canadá) y el **Sr. Ghia** (Italia) expresan su apoyo a que se incluya, en el párrafo 18, la oración que propuso el representante del Reino Unido y la que propuso el representante de los Estados Unidos.
32. **El Presidente** dice que entiende que la Comisión conviene en incluir en el párrafo 18 la oración propuesta por el representante del Reino Unido, seguida por la oración propuesta por el representante de los Estados Unidos.
33. *Así queda acordado.*
34. *Se aprueba la sección del proyecto de informe que figura en el documento A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.8, en su forma enmendada.*
- Se levanta la sesión a las 15.05 horas.*

**Acta resumida de la 976ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
Viena, el lunes 22 de julio de 2013, a las 9.30 horas**

[A/CN.9/SR.976]

Presidente: Sr. Schödl (Suiza)

Se declara abierta la sesión a las 9.40 horas.

Labor prevista y posible labor futura, entre otras cosas en los ámbitos del arbitraje y la conciliación, el fraude comercial, el comercio electrónico, el régimen de la insolvencia, el derecho contractual internacional, las microfinanzas, la solución de controversias en línea, la contratación pública y el desarrollo de infraestructuras, incluida la colaboración entre el sector público y el sector privado, y las garantías reales (A/CN.9/752 y Add.1; A/CN.9/774; A/CN.9/789)

1. El **Presidente** propone que la Comisión examine en primer lugar su enfoque estratégico respecto del establecimiento de prioridades para la labor futura, teniendo en cuenta la escasez de recursos en años recientes. A continuación, la Comisión examinará la aplicación práctica de su enfoque estratégico en relación con los proyectos en curso. Invita a la secretaría a presentar la primera parte del debate.

2. La **Sra. Nicholas** (Secretaría) señala a la atención de la Comisión los documentos A/CN.9/752 y Add.1, sobre “Un rumbo estratégico para la CNUDMI”, que fueron preparados por la secretaría para el período de sesiones anterior, y el documento A/CN.9/774, relativo a la labor prevista y posible labor futura. En el párrafo 5 del documento A/CN.9/774 figura otra lista de informes pertinentes.

3. En vista de la valiosa experiencia adquirida en años recientes por muchos Estados en relación con la utilización óptima de los escasos recursos, la Comisión y la secretaría agradecerían todo asesoramiento que esos Estados puedan prestarles sobre la adopción de un enfoque estratégico de la distribución de las tareas. Refiriéndose al título del documento A/CN.9/774, “Labor prevista y posible labor futura”, la oradora dice que se invita a la Comisión a determinar el alcance de todas las actividades de la CNUDMI para el año entrante. Por tanto, deberá determinar las actividades que han de emprenderse y especificar cuándo y cómo han de realizarse. Las actividades incluyen no solo la labor legislativa sino también, por ejemplo, la asistencia técnica, la coordinación y cooperación con otros órganos pertinentes y la promoción de la interpretación uniforme de los textos.

4. Con respecto a la labor legislativa, la secretaría ha compilado diversas opiniones y observaciones expresadas anteriormente por la Comisión. Por ejemplo, la Comisión ha tomado nota de las restricciones impuestas por el poco tiempo durante el cual se dispondrá de servicios de conferencias para sus deliberaciones oficiales. En los cuadros 1 y 2 del documento A/CN.9/774 se señalan 10 temas sustantivos relacionados con la labor legislativa. Resumiendo los debates celebrados durante las dos semanas anteriores del período de sesiones, la oradora dice que se han hecho recomendaciones en la esfera del arbitraje y la conciliación respecto de la elaboración de una convención sobre la transparencia, junto con la redacción de notas sobre la organización de los procedimientos arbitrales y posibles procedimientos concurrentes y paralelos. En la esfera del comercio electrónico, se ha recomendado la continuación de la labor relativa a los documentos transmisibles electrónicos. Sin embargo, aún ha de determinarse si debería ampliarse esa labor para incluir temas relacionados con la gestión de la identidad, las ventanillas únicas y el comercio móvil. Continuará la labor prevista en el mandato actual, incluida la relacionada con el centro de los principales intereses y las obligaciones de los directores. En el ámbito de las operaciones garantizadas, se propone continuar la labor relativa a la formulación de la Ley Modelo, con sujeción a ulteriores deliberaciones sobre las prioridades, que podrían incluir las garantías reales sobre valores no intermediados.

5. Dado que en el año próximo solo se dispondrá de 12 semanas de servicios de conferencias, es evidente que será necesario establecer prioridades entre los temas mencionados. La Comisión tal vez desee considerar la posibilidad de establecer un cierto número de principios generales aplicables a la evaluación de las prioridades para la labor futura a fin de promover un enfoque a la vez estratégico y coherente. La Comisión ha reconocido repetidamente la importancia de formular textos legislativos en el marco de períodos de sesiones de grupos de trabajo. La ventaja comparativa que tienen los textos de la CNUDMI es que son universalmente aplicables y, por consiguiente, ampliamente aceptados. Otro factor relevante es la publicación de los proyectos de texto por adelantado. Los contados textos de la CNUDMI que se han formulado excepcionalmente fuera de ese entorno son por lo general

menos reconocidos y utilizados. Por tanto, la Comisión tal vez desee reafirmar la importancia de la formulación de textos legislativos por los grupos de trabajo.

6. Al establecer prioridades, la Comisión tradicionalmente selecciona los temas en términos de su importancia pero también en función de su urgencia. En la sección del documento A/CN.9/774 titulada “Establecimiento de prioridades con respecto a las esferas temáticas” se pasa revista a la evolución del enfoque adoptado por la Comisión en relación con esta cuestión desde su creación en 1968. Se ha observado desde el comienzo que la armonización se logra con más facilidad en las ramas técnicas del derecho que en las materias íntimamente vinculadas con las tradiciones nacionales y los principios fundamentales del derecho interno. Por otra parte, se ha reconocido la importancia de centrar la atención en esferas en que existe una necesidad económica de armonización y en que puede preverse un efecto beneficioso para el comercio internacional. En tercer lugar, es importante tener presentes las posibilidades de aprovechar lo que se ha denominado el efecto de “irradiación”. Así pues, incluso si los Estados no aprueban un texto de la CNUDMI en su totalidad, podrían adoptarse y aplicarse de diversas maneras sus principios y disposiciones básicas.

7. En los documentos que la Comisión tuvo ante sí en su 45º período de sesiones, celebrado en 2012, se le invitó a que tuviera en cuenta las funciones y la pertinencia de las actividades de la CNUDMI en el marco de la agenda general de las Naciones Unidas y las prioridades de las comunidades de donantes y los gobiernos nacionales. Otro principio importante es garantizar el equilibrio entre las actividades legislativas y de apoyo de la CNUDMI, en otras palabras, armonizar el desarrollo legislativo en el marco de los períodos de sesiones y las actividades que lleva a cabo la secretaría, de ser necesario con la participación de expertos. Entre otras cuestiones cabe mencionar la movilización de recursos adicionales, incluidas las actividades colaborativas, cuando proceda.

8. La Comisión tal vez desee plantearse algunas preguntas de carácter general antes de decidir si asigna un tema a un grupo de trabajo. La secretaría ha compilado una lista de ejemplos para que la Comisión los examine. El primero consiste en considerar si es probable que el tema dé lugar a consenso o si es innecesariamente polémico y poco conducente a lograr la armonización y la formulación de un texto viable. Lo segundo que cabe preguntarse es si es suficientemente probable que un texto legislativo redunde en un mejoramiento del derecho mercantil internacional. La tercera pregunta que hay que plantearse

es si el alcance del tema y las cuestiones de política que han de tratarse en un texto legislativo son suficientemente claros. Por último, conviene preguntarse si en otros órganos se están realizando actividades de esa índole con respecto a temas análogos.

9. La Comisión tal vez desee tener presente asimismo el ciclo de vida de un texto de la CNUDMI tal como se señala en el documento A/CN.9/752. En los grupos de trabajo y los coloquios se ha expresado la opinión de que las actividades más informales pueden ser especialmente útiles, por ejemplo en el marco de la preparación de textos para su presentación a los grupos de trabajo. Sin embargo, los asuntos de política y las cuestiones sustantivas de redacción deberían por lo general ser tratadas por un grupo de trabajo. Recientemente se ha hecho mucho hincapié en la importancia de aprovechar todos los recursos de conferencias de que dispone la CNUDMI. La utilización de coloquios podría considerarse una especie de enfoque intermedio entre los métodos de trabajo formales e informales habida cuenta de que los coloquios que se celebran durante las conferencias pueden atraer a un nutrido público y las actuaciones pueden llevarse a cabo en todos los idiomas de trabajo de las Naciones Unidas. Con una planificación suficiente fuera del actual período presupuestario, la secretaría podría organizar coloquios en lugares de destino distintos de Nueva York y Viena con limitadas consecuencias financieras. También podría ser provechoso para la secretaría celebrar reuniones conjuntas con otros órganos pertinentes, como los bancos regionales de desarrollo.

10. Hay una creciente demanda, especialmente por parte de los países en desarrollo, de actividades encaminadas a promover la aprobación y el uso de textos de la CNUDMI, los cuales requieren un cierto nivel de comprensión de las políticas y los procedimientos previstos en ellos. Es esencial tener en cuenta el contexto social y las tradiciones jurídicas del país de que se trate. La secretaría está intentando realizar un mayor número de actividades de asistencia técnica, pero la escasez de recursos es un problema importante a ese respecto. Por tanto, la Comisión tal vez desee estudiar la forma de promover un equilibrio entre el desarrollo legislativo formal e informal y prestar apoyo suficiente a la asistencia técnica sin interrumpir la labor de carácter más formal. Si, por ejemplo, se decide iniciar trabajos en el marco de coloquios, será necesario adoptar medidas para impedir una interrupción de los ulteriores períodos de sesiones de los grupos de trabajo.

11. La oradora señala a la atención de la Comisión la sugerencia contenida en el párrafo 43 del documento A/CN.9/774 de que se asigne tiempo, en las reuniones de

la CNUDMI, para que los Estados compartan información sobre sus iniciativas destinadas a promover los instrumentos de la CNUDMI. En el último párrafo de ese documento se destaca el hecho de que cada vez resulta más difícil garantizar la publicación simultánea de los documentos en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Este es un problema particularmente pertinente en la esfera de la asistencia técnica.

12. **El Presidente** invita a la Comisión a examinar varias cuestiones básicas en materia de estrategia. La primera de ellas es la de determinar si se debería seguir confiando a los grupos de trabajo la responsabilidad de realizar tareas básicas de la Comisión y qué condiciones debe reunir un tema para que pueda ser asignado a un grupo de trabajo. Por ejemplo, el tema debería ser más técnico que político, debería tener repercusiones para el comercio internacional y estar bien delimitado. Es importante asimismo evitar la duplicación de la labor que realizan otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. El orador invita asimismo a la Comisión a formular observaciones sobre la complementariedad de los procedimientos de trabajo formales e informales. Por ejemplo, ciertas tareas pueden delegarse a la secretaría o a otros foros informales. Además, se invita a las delegaciones a expresar sus opiniones sobre la cooperación con otras organizaciones interestatales y sobre el papel futuro de la asistencia técnica.

13. **El Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) señala a la atención de la Comisión el documento A/CN.9/789, que contiene una propuesta de los Estados Unidos sobre la labor futura de la Comisión. Con respecto a la sostenibilidad de los grupos de trabajo, los Estados Unidos estiman que la Comisión no debería seguir basando sus prioridades de trabajo en un sistema de seis grupos de trabajo semipermanentes con títulos que los confinan a una esfera particular del derecho. Si se modifican los nombres y la estructura de los grupos de trabajo resultará más fácil a la Comisión revisar los proyectos en curso anualmente. Destaca asimismo la importante contribución de la secretaría. Como se observa en el documento A/CN.9/752, relativo a un rumbo estratégico de la CNUDMI, la secretaría ha elaborado los proyectos de texto de la Guía Jurídica sobre Transferencias Electrónicas de Fondos y de la Guía Legislativa sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada y los ha remitido directamente a la Comisión. La redacción de los textos sobre temas altamente técnicos puede confiarse a expertos o relatores especiales y presentarse posteriormente a la Comisión para que los examine. Si esas versiones no se consideran apropiadas pueden entonces remitirse a un grupo de trabajo.

14. El orador concuerda con las observaciones de la secretaría con respecto a los temas a los que debería asignarse prioridad. Los temas seleccionados deberían tener un efecto favorable en el comercio internacional. Otro criterio debería ser el efecto que una propuesta vaya a tener en el desarrollo económico inclusivo y el estado de derecho, en particular en los países en desarrollo. Señala a la atención de la Comisión la siguiente decisión adoptada por la CNUDMI en 1978 y citada en el documento A/CN.9/789: “por norma general, la Comisión no debía remitir temas a un grupo de trabajo sino después de que la Secretaría hubiese realizado estudios preparatorios y el examen de esos estudios por la Comisión hubiese indicado que el tema era no sólo adecuado sino que además la labor preparatoria estaba suficientemente avanzada para que un grupo de trabajo iniciase su labor de manera fructífera”. Además, la Comisión no debería duplicar la labor de otras entidades internacionales.

15. Con respecto a la movilización de recursos adicionales, es fundamental la coordinación con los órganos internacionales, en particular organizaciones como el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (“UNIDROIT”) y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. La CNUDMI ha colaborado recientemente con esas organizaciones en la publicación de un estudio sobre las garantías reales. El orador sugiere que la CNUDMI podría colaborar asimismo con la Conferencia de La Haya sobre un proyecto relativo a las fuentes del derecho, una esfera en la que esa organización ha adquirido considerable pericia. De modo similar, el UNIDROIT se especializa en la esfera del derecho contractual. En la reunión de su Consejo de Administración celebrada en mayo de 2013, el UNIDROIT dio su firme apoyo a la idea de una cooperación sustantiva con la CNUDMI en la elaboración conjunta de instrumentos.

16. Dados los escasos recursos disponibles, no puede esperarse que la secretaría preste asistencia técnica detallada. No obstante, puede actuar como centro de coordinación de esa asistencia; en este sentido, su delegación es partidaria de establecer un mayor número de centros regionales. Por último, todos los Estados tienen la responsabilidad de promover proyectos de asistencia técnica.

17. **El Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que cuando la Comisión decidió duplicar el número de grupos de trabajo, asignó un número y no un título a cada grupo. El título, mencionado entre corchetes a continuación del número del grupo, tiene por objeto simplemente indicar a las delegaciones su ámbito de especialización. Los grupos

de trabajo se reconstituyen formalmente cada año y se les asigna un mandato específico.

18. La **Sra. Nicholas** (Secretaría) hace hincapié en que la elaboración de textos fuera de la estructura de los grupos de trabajo ocurre solo en circunstancias excepcionales. Mientras que las etapas iniciales o las etapas técnicas de redacción final pueden realizarse fuera de ese entorno, las cuestiones normativas y sustantivas se tratan en el marco de los grupos de trabajo para garantizar que el resultado sea ampliamente aceptable.

19. El **Sr. Fruhmann** (Austria) conviene en que los textos jurídicos deberían elaborarse en el marco de los grupos de trabajo a fin de asegurar el carácter inclusivo del proceso. Sin embargo, eso no excluye la participación de órganos externos, como las organizaciones internacionales, en la preparación de los textos.

20. Con respecto a los ámbitos de especialización de los grupos de trabajo, una opción mencionada en el documento A/CN.9/774 es que cada grupo de trabajo se ocupe de más de un tema a la vez.

21. Sobre la cuestión de la priorización, los criterios relativos al efecto en el derecho mercantil internacional, el efecto de “irradiación” y el valor añadido previsto son de gran importancia. No obstante, su delegación no está del todo convencida de que el criterio adicional sugerido en el párrafo 29 del documento A/CN.9/774 entre en esa categoría. Solicita a la secretaria que aclare la idea en que se basa esa sugerencia.

22. Refiriéndose a los recursos necesarios para la publicación de los documentos de la CNUDMI en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, pregunta si es realmente necesario disponer de la traducción de todos los documentos a los seis idiomas. Pueden lograrse ahorros considerables si se adopta un sistema simplificado que se base más en la documentación electrónica que en la impresa.

23. La **Sra. Nicholas** (Secretaría), respondiendo a la pregunta relativa al párrafo 29 del documento A/CN.9/774, dice que el criterio adicional se propuso en el documento A/CN.9/752/Add.1 a la luz de la función y la pertinencia de la CNUDMI tanto en el contexto de las Naciones Unidas como en el ámbito del comercio y las relaciones comerciales. Su labor en la esfera del derecho mercantil internacional tiene por objeto apoyar el desarrollo sostenible e inclusivo y el estado de derecho mediante la armonización de las disposiciones jurídicas pertinentes. En consecuencia, la Comisión tal vez desee tener presentes los tipos de actividades que respaldarían más directamente esos objetivos. Por ejemplo, la CNUDMI podría apoyar la

aplicación de las disposiciones de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo en relación con el estado de derecho, la gobernanza y la lucha contra la corrupción. La labor de la CNUDMI en materia de contratación pública es actualmente de gran utilidad para los custodios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y para algunos de los bancos multilaterales de desarrollo, que la aplican con miras a mejorar la gobernanza en la esfera de la contratación pública.

24. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que se asigna gran importancia a la publicación de los trabajos de la Comisión en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Sin embargo, ya no se envían voluminosas remesas de documentos impresos de un lugar de destino a otro. Se están adoptando medidas para reducir al mínimo la cantidad de documentación impresa en papel.

25. El **Sr. Bellenger** (Francia) hace hincapié en la conveniencia de actualizar los métodos de trabajo de la Comisión y sugiere que en todos los futuros periodos de sesiones la planificación estratégica forme parte de las deliberaciones. Con respecto a las propuestas formuladas por el representante de los Estados Unidos, si bien reconoce el valor de un enfoque basado en la autorización de cada proyecto y la asignación de ciertas tareas a expertos, insiste en que la redacción de los textos legislativos de la CNUDMI debe hacerse en el marco de los grupos de trabajo. De lo contrario no podría garantizarse la necesaria transparencia respecto de los Estados miembros de la Comisión. Por tanto, es preciso seguir reflexionando sobre esta cuestión a fin de alcanzar la meta de lograr una mayor flexibilidad.

26. Su delegación sugiere que el Presidente de la Comisión sea nombrado por el año civil y no por el periodo entre dos sesiones plenarias. Conforme al sistema actual, las obligaciones del Presidente se limitan a presidir las sesiones. Si el Presidente fuera elegido antes de una sesión plenaria podría apoyar la organización de las actuaciones.

27. El **Sr. Schoefisch** (Alemania) dice que el sistema basado en los grupos de trabajo ha funcionado muy bien hasta la fecha. Por tanto, si bien es conveniente conservarlo, debería preverse un enfoque más orientado a los proyectos y un mayor grado de flexibilidad. No es necesario que los seis grupos de trabajo se reúnan cada año. Cuando un grupo de trabajo no tiene ningún tema urgente que tratar, podría transferirse el tiempo de reunión que le corresponde a otro grupo de trabajo con un mayor volumen de trabajo. Si un grupo de trabajo estima que puede tratar más de un tema ello debería permitírsele,

aunque en su opinión es preferible que se encargue de un solo tema en cada oportunidad.

28. Las actuaciones de los grupos de trabajo son la mejor garantía de transparencia. Sin embargo, la labor preparatoria puede realizarse fuera de ese contexto, por ejemplo en el marco de un coloquio.

29. La asistencia técnica es de suma importancia y debería ser una función de la secretaría, siempre y cuando ello no interfiera en la tarea de preparar las actuaciones de la Comisión y los grupos de trabajo. Los Estados miembros también deberían prestar asistencia técnica en la forma y en el momento apropiados.

30. La coordinación y los proyectos conjuntos con otros órganos, como el UNIDROIT y la Conferencia de La Haya, también son de gran relevancia.

31. El **Sr. Shautsou** (Belarús) apoya la idea de actualizar los métodos de trabajo de la CNUDMI. Si bien ciertos proyectos pueden asignarse a expertos, esos proyectos deberían ser de carácter esencialmente técnico, como la compilación de glosarios y material de referencia. La labor más valiosa que realiza la CNUDMI es la elaboración de textos legislativos y en algunos casos de textos informales. Ayuda a los Estados a pasar de un enfoque limitado de alcance regional o especializado a un enfoque internacional y a equilibrar intereses diversos.

32. Su delegación conviene en que la coordinación de la labor con otros órganos internacionales, como el UNIDROIT y La Haya, es sumamente importante.

33. El **Sr. Rodríguez** (Suiza) expresa apoyo con respecto al enfoque estratégico de la labor futura y a los cuatro criterios básicos que han de aplicarse para determinar los proyectos futuros.

34. No sería razonable adoptar un enfoque prescriptivo respecto de la relación entre las reuniones formales e informales. Habida cuenta de la escasez de recursos, es fundamental aprovechar al máximo los recursos disponibles. Por consiguiente, su delegación es partidaria de los enfoques innovadores y de la flexibilidad a la hora de organizar coloquios o reuniones conjuntas. El orador entiende la preocupación por la posible perpetuación de los grupos de trabajo semipermanentes y subraya la necesidad de respetar los criterios aplicables a la labor futura. No obstante, también cabe reconocer el valor de esos grupos de trabajo, pues la pericia que han desarrollado a lo largo del tiempo es única. En muchos casos, el resultado de su labor es inconcebible fuera de ese contexto.

35. El **Sr. Maradiaga** (Honduras) dice que las secciones A, B y C de la parte IV del documento A/CN.9/774, relativas a la asignación de recursos y el establecimiento de prioridades, contienen un resumen exacto de las cuestiones principales que tratará la Comisión. En algunos casos, otros órganos internacionales, como el UNIDROIT, se ocupan simultáneamente de proyectos que pertenecen a la esfera de competencia de la CNUDMI. Dado que varias organizaciones diferentes pueden estar dedicando personal, recursos e infraestructura a la misma tarea, es esencial establecer estrechos vínculos con las organizaciones regionales e internacionales a fin de establecer prioridades.

36. El orador propone que se pida a la secretaría que estudie la posibilidad de reducir el número de grupos de trabajo en vista de la falta de recursos. Una posibilidad sería, por ejemplo, combinar los grupos de trabajo sobre arbitraje y conciliación, solución de controversias en línea y comercio electrónico.

37. El **Sr. Chan Wah Teck** (Singapur) dice que su delegación apoya las propuestas contenidas en el documento A/CN.9/789, presentado por los Estados Unidos. Dado que en las circunstancias actuales es vital garantizar la utilización óptima de los recursos mediante la adopción de un enfoque estratégico y el establecimiento de prioridades, su delegación también apoya plenamente las propuestas presentadas por la secretaría. Un factor decisivo en ese contexto es el mandato de la CNUDMI de fomentar la modernización y armonización del derecho mercantil internacional. Los temas que no entren en el ámbito de ese mandato deberían preferentemente dejarse a otros organismos que disponen de los conocimientos especializados necesarios. En el documento A/CN.9/789 figura una crítica implícita de algunos grupos de trabajo que supuestamente quieren perpetuar su existencia. Esos grupos de trabajo no están definidos por un número sino por una temática y se han arrogado el derecho exclusivo de tratar los temas respectivos. Si bien los grupos de trabajo semipermanentes cuentan con gran pericia, es inadmisibles que sigan funcionando en un entorno de escasez de recursos y ocupándose de temas que excluyen la labor sobre otras cuestiones más urgentes.

38. Los grupos de trabajo están integrados por representantes de Estados y su mandato básico consiste en preparar textos jurídicos que sean ampliamente aceptables a nivel internacional. El orador pregunta si instrumentos no vinculantes, como las guías, que no establecen normas y no son de carácter obligatorio, pueden considerarse textos jurídicos. Podría ser preferible asignar esas tareas a expertos que trabajen en colaboración con la secretaría.

Los textos resultantes podrían entonces ser examinados y aprobados por la Comisión. A este respecto, remite al párrafo 20 del documento A/CN.9/779, relativo a las alianzas público-privadas, en el que se señala que los instrumentos sobre proyectos de infraestructura con financiación privada no son muy conocidos y que no habían sido de mucha utilidad para los legisladores y reguladores. El orador se declara apenado por esa conclusión, pues presidió la sesión de la Comisión que aprobó la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada. Sin embargo, es evidente que la Guía no es un texto jurídico y no establece normas jurídicas vinculantes.

39. La asistencia técnica es sumamente importante y debería tener prioridad incluso si hay escasez de recursos debido a que los países en desarrollo dependen de ella. Los Estados que están considerando la posibilidad de adoptar textos jurídicos complejos de la CNUDMI requieren asesoramiento especializado sobre la forma de aplicar esos textos en la práctica. Idealmente, los expertos de la CNUDMI deberían brindar orientación personal a los funcionarios competentes de esos Estados.

40. La CNUDMI debería asegurar la coordinación con otros organismos internacionales que se ocupan del derecho mercantil internacional en el sistema de las Naciones Unidas a fin de evitar la duplicación y garantizar la utilización óptima de los escasos recursos. Es necesario examinar cuidadosamente los procedimientos internos de las Naciones Unidas antes de formular recomendaciones específicas a ese respecto. No obstante, el orador confía en que las modalidades de coordinación podrán formularse a su debido tiempo.

41. La **Sra. Talero** (Colombia) apoya las propuestas contenidas en el documento A/CN.9/789, presentado por los Estados Unidos. Destaca la referencia a los textos de carácter técnico elaborados de manera informal por la secretaría con contribuciones de expertos y sin negociaciones previas en el marco de un grupo de trabajo. En general, esos textos son objeto de amplio reconocimiento por los Estados miembros de la Comisión.

42. La **Sra. Sabo** (Canadá) está de acuerdo con el representante de Francia en que la planificación estratégica y el establecimiento de prioridades deberían examinarse en todos los futuros períodos de sesiones de la Comisión.

43. Concuera con el representante de Alemania en que el sistema de los grupos de trabajo debería ser flexible. Cuando la Comisión decidió aumentar el número de grupos de trabajo de tres a seis, convino en que ese número podía modificarse en circunstancias excepcionales. Los

factores decisivos son el número de proyectos que decida abordar la Comisión, los métodos de trabajo utilizados para agilizar los proyectos y los recursos disponibles a la secretaría y los Estados.

44. Con respecto a la labor informal, la oradora estima que la secretaría puede preparar algunos textos de carácter técnico e incluso jurídico siempre y cuando sean examinados por la Comisión o un grupo de trabajo.

45. Su delegación concuerda en general con los criterios de selección de proyectos enunciados en el documento A/CN.9/774. Refiriéndose a los párrafos 28 y 29, dice que el papel y la pertinencia de la CNUDMI en el contexto de la labor y las prioridades de las Naciones Unidas, las comunidades de donantes y las prioridades de los diversos gobiernos deberían tenerse en cuenta, aunque esos factores no deberían constituir los criterios principales a la hora de seleccionar los proyectos.

46. Su delegación apoya enérgicamente la propuesta del representante de los Estados Unidos con respecto a la labor conjunta con organizaciones como el UNIDROIT. La oradora sugiere que la Comisión tome nota del apoyo a la cooperación sustantiva con la CNUDMI expresado por el Consejo de Administración del UNIDROIT y emprenda activamente la selección de un proyecto conjunto apropiado.

47. Aunque algunos documentos se publican en el sitio web de la CNUDMI antes de que estén disponibles en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, la oradora estima que posteriormente deberían estar disponibles en todos esos idiomas.

48. El **Sr. Leinonen** (Observador de Finlandia) hace suya la opinión de que la planificación estratégica y el establecimiento de prioridades deberían incluirse en el programa de todos los períodos de sesiones futuros de la Comisión.

49. Los criterios de selección mencionados en el documento A/CN.9/774 son sumamente pertinentes y deberían tenerse presentes al decidir los temas que han de abordar los grupos de trabajo.

50. Los principios que se aplican a la organización de los trabajos son básicamente razonables y ese marco no excluye el logro de una mayor flexibilidad. No es necesario asignar el mismo número de días de reunión a cada grupo de trabajo. Cuando proceda, debería asignarse más tiempo a los proyectos más urgentes y darse prioridad a la labor legislativa. Si bien los instrumentos jurídicos no vinculantes son muy importantes, no parece razonable que los grupos de trabajo dediquen mucho tiempo a ese tipo de

documentos. El orador no se opone a la idea de asignar más de un tema a un determinado grupo de trabajo, siempre y cuando la Comisión le dé un mandato definido.

51. Su delegación es muy partidaria de la cooperación sustantiva con otras organizaciones. Concuera con la representante del Canadá en que la Comisión debería tomar nota de la decisión pertinente del Consejo de Administración del UNIDROIT y hacer lo necesario para seleccionar un proyecto conjunto.

52. La **Sra. Marcucci** (Italia) dice que los criterios para establecer las prioridades enunciados en el documento A/CN.9/774 deberían servir de guía para la evaluación de los proyectos en curso y la posible labor futura. El problema de la escasez de recursos no debería abordarse de forma que altere la estructura y el alcance del mandato asignado a la CNUDMI. Es importante mantener como norma general que el mandato se cumpla en el marco de los grupos de trabajo a fin de promover la legitimidad y la transparencia de los textos elaborados por la Comisión. Ese principio no excluye la posibilidad de confiar el análisis de la documentación técnica a grupos de expertos.

53. La cooperación con otras organizaciones ha demostrado ser muy productiva y debería continuarse.

54. El **Sr. Estrella Faria** (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado – UNIDROIT) dice que en su período de sesiones de mayo de 2013, el Consejo de Administración del UNIDROIT confirmó su firme interés por reanudar su larga práctica consistente en cooperar con órganos de las Naciones Unidas en la formulación de textos jurídicos y la realización de actividades conjuntas. Dado que la CNUDMI es la candidata natural para esa clase de cooperación, el Consejo de Administración agradecerá toda medida que adopte la Comisión con miras a identificar un tema apropiado de cooperación futura.

55. El **Presidente**, resumiendo el debate, dice que se ha expresado amplio apoyo a los criterios para el establecimiento de prioridades propuestos por la secretaría. Se ha tomado nota de que el mandato de la Comisión de fomentar la modernización y armonización del derecho mercantil internacional sigue vigente, incluso en una situación de escasos recursos. La formulación de textos en el marco de los grupos de trabajo se ha mencionado como una de las principales ventajas comparativas de la Comisión, que realzan la transparencia y la legitimidad de los textos resultantes. Se ha puesto de relieve asimismo la importancia del enfoque multilingüe. A la vez que se ha expresado preocupación por la posibilidad de que los grupos de trabajo se perpetúen indefinidamente, también se ha tomado nota de las ventajas derivadas de la

acumulación de conocimientos especializados. Varios oradores hicieron hincapié en que debería darse prioridad a la redacción de textos jurídicos frente a instrumentos no vinculantes como las guías legislativas. En respuesta a la sugerencia de que la Comisión adopte un enfoque más centrado en los proyectos, se ha señalado que la actual práctica de los grupos de trabajo ya brinda flexibilidad suficiente a esos efectos.

56. A juicio de los oradores, la labor informal es una opción de carácter excepcional y la labor puramente técnica solo debería confiarse a la secretaría o a expertos externos. La secretaría debería disponer de suficiente flexibilidad para organizar esa labor del modo más apropiado según el caso.

57. Se ha subrayado que la CNUDMI no es una organización regional sino mundial. Las ventajas que su efecto positivo en el comercio internacional tiene para los países en desarrollo son muy favorables. Sin embargo, el mandato de la Comisión y sus efectos secundarios no deberían invertirse. Se recalcó la importancia de la asistencia técnica prestada por la secretaría y los Estados.

58. Muchos oradores han instado a la Comisión a establecer vínculos eficaces con organizaciones que se ocupan de ámbitos similares y a promover la coordinación tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas. La Comisión también ha tomado nota de la invitación cursada por el UNIDROIT a establecer una relación de cooperación más formal. Se expresaron diversas opiniones sobre si la Comisión debería armonizar sus prioridades de trabajo con las de esos otros órganos de las Naciones Unidas.

59. Por último, se recomendó que en el programa de los futuros períodos de sesiones de la Comisión se incluyese el debate sobre la planificación estratégica y el establecimiento de prioridades.

Se suspende la sesión a las 11.35 horas y se reanuda a las 12.10 horas.

60. El **Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones sobre su resumen del debate.

61. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) hace hincapié en la importancia de tener en cuenta el estado de derecho al priorizar los temas. Señala nuevamente a la atención de la Comisión la referencia hecha por su delegación, en el documento A/CN.9/789, a una decisión de la Comisión de 1978 relativa, entre otras cosas, a los estudios preparatorios realizados por la secretaría. Por último, parece existir consenso en el sentido de que los documentos preparados por grupos de expertos o reuniones

regionales sean sometidos a examen por un grupo de trabajo o por la Comisión.

62. El **Sr. Fruhmann** (Austria) expresa reservas con respecto a los párrafos 28 y 29 de la sección del documento A/CN.9/774 relativa a la priorización de las esferas temáticas, especialmente a la referencia a un enfoque simbiótico de las actividades de las Naciones Unidas, las comunidades de donantes y los gobiernos nacionales.

63. El **Sr. Bellenger** (Francia) dice que será difícil que la CNUDMI se centre principalmente en los textos legislativos a expensas de los instrumentos jurídicos no vinculantes, pues a menudo comienza su labor sobre determinadas esferas con la elaboración de guías legislativas no vinculantes y solo en una etapa posterior prepara textos de carácter más vinculante.

64. Observa que varias delegaciones han expresado apoyo a la propuesta de que la labor se realice sobre la base de proyectos. Se ha sugerido asimismo que los mandatos de los grupos de trabajo se definan de forma más pormenorizada.

65. El orador reitera su propuesta de que el Presidente de la Comisión sea elegido por un año civil y no por el intervalo entre períodos entre sesiones.

66. El **Sr. Chan Wah Teck** (Singapur) dice, a efectos de aclaración, que su delegación no se opone a que la CNUDMI prepare textos no vinculantes. Sin embargo, cuestiona la idoneidad de asignar esas tareas a los grupos

de trabajo. Con respecto a la observación formulada por el representante de Francia, señala que a veces los grupos de trabajo comienzan preparando un texto legislativo y luego, como seguimiento a este, elaboran un instrumento no vinculante. Añade que en los mandatos de los grupos de trabajo se debería especificar el resultado previsto de las deliberaciones.

67. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que la historia de la CNUDMI demuestra la dificultad de elaborar definiciones detalladas de los mandatos de los grupos de trabajo y sus resultados previstos. A modo de ejemplo, menciona la Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente. En un principio, la secretaría elaboró un documento basado en un análisis intensivo del tema. Las deliberaciones sobre ese documento continuaron durante varios años antes de que se asignara a un grupo de trabajo el mandato de redactar una ley modelo. Por razones técnicas, tras varios períodos de sesiones el grupo de trabajo optó por elaborar una convención y obtuvo la aprobación de esa decisión por parte de la Comisión.

68. El **Sr. Zhang** Chenyang (China) apoya el sistema de los grupos de trabajo, el enfoque multilingüe y la modernización y armonización del derecho mercantil internacional. Sin embargo, en una época de escasez de recursos, debería asignarse especial importancia a la flexibilidad, que es un requisito básico para la eficacia de la labor de la CNUDMI y su secretaría.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

**Acta resumida de la 977ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
Viena, el lunes 22 de julio de 2013, a las 14.00 horas**

[A/CN.9/SR.977]

Presidente: Sr. Schöll (Suiza)

Se declara abierta la sesión a las 14.05 horas.

Centros regionales de la CNUDMI (A/CN.9/775)

1. El **Presidente** da la bienvenida al Viceministro de Asuntos Jurídicos de la República de Corea, Sr. Kang Chan Woo, e invita a la secretaría a presentar el tema del programa relativo a los centros regionales de la CNUDMI.

2. El **Sr. Castellani** (Secretaría) dice que en los párrafos 51 a 70 del documento A/CN.9/775 se describen las actividades realizadas durante el último año por el Centro Regional para Asia y el Pacífico de la CNUDMI, que se estableció en enero de 2012 y tiene su sede en la República de Corea. Entre los aspectos a los que se dio prioridad en la asistencia técnica cabe mencionar la promoción de la aprobación universal de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (la Convención de Nueva York). Además, los programas se adaptaron a las necesidades y solicitudes de los países de la región. En tal sentido, el orador destaca la cooperación del Centro con organizaciones regionales. Por ejemplo, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESAP) está preparando un instrumento sobre la facilitación del comercio sin soporte de papel y solicitó la asistencia del Centro Regional para los aspectos jurídicos del proyecto. Con la participación del Centro Regional, la Secretaría de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) están examinando el derecho del comercio electrónico y las transacciones electrónicas. Se ha prestado apoyo a la adopción por la República Democrática Popular Lao de una Ley sobre Operaciones Electrónicas. También se han celebrado reuniones de grupos de expertos sobre temas como la solución de controversias en línea y el uso de textos uniformes en la reforma del derecho contractual.

3. El **Sr. Kang** Chan Woo (República de Corea) dice que el Centro Regional para Asia y el Pacífico de la CNUDMI se estableció con el fin de promover en la región los textos normalizados de la CNUDMI y prestar asistencia jurídica a los Estados para su adopción. Con ese fin, el Ministerio de Justicia de la República de Corea puso a disposición un experto jurídico y procuró apoyar las

actividades del Centro. En 2012, el Ministerio y el Centro acogieron con éxito tres conferencias internacionales sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, comercio electrónico y solución de controversias en línea, y arbitraje en el comercio internacional, en las que se promovieron y compartieron los textos de la CNUDMI y la información pertinente. El Ministerio y el Centro también cooperaron en la prestación de asistencia a Myanmar para su adhesión a la Convención de Nueva York. En abril de 2013, Myanmar pasó a ser el 149º Estado parte en la Convención. El Ministerio prevé organizar más conferencias internacionales con el Centro Regional antes del final de 2013. Una de esas conferencias se dedicará a la creación de condiciones jurídicas adecuadas para las microempresas. Como parte de los esfuerzos de su país para prestar asistencia a sus vecinos, el Ministerio de Justicia y el Centro Regional están preparando un proyecto conjunto de investigación para ayudar a Mongolia a promulgar una legislación de arbitraje moderna. Además, la República de Corea prestó asistencia a la República Democrática Popular Lao en la reforma de su legislación sobre valores. En el contexto del proyecto de “Facilitación del Comercio” en Asia y el Pacífico, el Centro Regional y el Ministerio de Justicia están adoptando medidas a fin de mejorar las condiciones para la ejecución de los contratos.

4. Los impresionantes logros del Centro Regional en tan corto plazo son comparables a la rápida recuperación de su país tras las consecuencias ruinosas de la Guerra de Corea. En 1958, cuando se aprobó la Convención de Nueva York, un periodista hizo el comentario siguiente respecto de una Corea asolada por la guerra: “Esperar que la democracia florezca en Corea es como esperar que una rosa florezca en un cubo de basura”. Su error quedó claramente demostrado. La República de Corea es un país próspero. Como nación que ha superado obstáculos enormes en un lapso relativamente breve, su país está ansioso de compartir sus conocimientos con los vecinos de la región. Es, pues, adecuado que se haya elegido a la República de Corea para albergar el primer Centro Regional de la CNUDMI, y el Ministerio de Justicia prestará un apoyo inquebrantable a la ejecución del mandato de la CNUDMI.

5. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) felicita al Centro Regional y al Gobierno de Corea por los excelentes

resultados logrados hasta el momento. Dice que asistió a las conferencias regionales celebradas en el Centro sobre comercio electrónico, solución de controversias en línea y derecho contractual internacional. La CNUDMI puede ser un centro de información eficaz para la asistencia técnica, pero los Estados también deben participar activamente. Las conferencias ofrecieron a los Estados una oportunidad excelente de examinar y coordinar la aplicación de los instrumentos de la CNUDMI.

6. El **Sr. Okemwa** (Kenya) dice que el Gobierno de Kenya se ha comprometido a establecer un centro regional. La nueva administración ha comenzado a examinar los mecanismos adecuados, y mantendrá informada a la secretaría de la CNUDMI de los progresos a ese respecto.

Labor prevista y posible labor futura, entre otras cosas en los ámbitos del arbitraje y la conciliación, el fraude comercial, el comercio electrónico, el régimen de la insolvencia, el derecho contractual internacional, las microfinanzas, la solución de controversias en línea, la contratación pública y el desarrollo de infraestructuras, incluida la colaboración entre el sector público y el sector privado, y las garantías reales (continuación) A/CN.9/752 y Add.1, 774, 780, 789 y 790)

7. El **Presidente** invita a la secretaría a presentar los temas de la segunda parte del debate de la Comisión sobre el tema 16 del programa.

8. La **Sra. Nicholas** (Secretaría) dice que hay diez temas que se pueden examinar con respecto a la labor futura. La secretaría considera que en el período de sesiones en curso la Comisión ya ha adoptado decisiones respecto de los temas siguientes: arbitraje, comercio electrónico, insolvencia, solución de controversias en línea y operaciones garantizadas. Falta examinar el fraude comercial, el derecho contractual internacional, las microfinanzas y la creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, y la colaboración entre los sectores público y privado.

9. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que, en el caso de la insolvencia, no se ha adoptado una decisión final sobre la celebración de un coloquio en vez de una reunión del Grupo de Trabajo V de dos semanas de duración.

10. El **Presidente** conviene en que no se ha adoptado una decisión sobre ese tema. Sin embargo, en primer término la Comisión debería aclarar su posición respecto de los temas pendientes mencionados por la secretaría. El fraude

comercial es el primero de esos temas, que se enumeran en el párrafo 11 del documento A/CN.9/774.

11. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que por el momento no hay propuesta alguna sobre la preparación de un instrumento nuevo, ni se ha pedido tiempo para reuniones o la creación de un grupo de trabajo. Hace varios años la Comisión publicó unos indicadores de fraude comercial que se consideraron útiles. En el 45º período de sesiones, celebrado en 2012, se propuso que la secretaría convocara un comité de expertos para examinar la posible actualización de esos indicadores. El comité confirmó en general que los indicadores seguían siendo pertinentes y sugirió que la secretaría siguiera convocando de tanto en tanto un grupo de expertos para evaluar la necesidad de una actualización.

12. La **Sra. Sabo** (Canadá) dice que no se debe dar prioridad a la labor sobre el fraude comercial. Una vigilancia básica de los indicadores por parte de la secretaría sería suficiente.

13. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que en el documento A/CN.9/789 los Estados Unidos expresaron su apoyo a la celebración de un coloquio sobre el fraude comercial, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En una reunión oficiosa de expertos organizada por la secretaría en abril de 2013 también se concluyó que un coloquio sobre el tema podría ser muy beneficioso. En esa reunión se destacó una decisión de la UNODC en que se instaba a elaborar una ley modelo sobre el robo de identidad y a promover la coordinación a ese respecto entre la UNODC y la CNUDMI. La UNODC podría centrar su atención en los aspectos relacionados con el consumidor, y la CNUDMI, en los aspectos empresariales del robo de identidad. En el coloquio también se podría abordar la cuestión del fraude comercial en el contexto de la resolución de controversias en línea y la transferibilidad electrónica de los documentos. Desde que en 2004 se celebró el primer coloquio sobre fraude comercial, el comercio electrónico ha crecido de manera exponencial. Su delegación tiene una postura flexible respecto de la fecha de celebración del coloquio, pero otorga gran importancia a la propuesta de celebrar reuniones conjuntas con la UNODC sobre el robo de identidad.

14. El **Sr. Schoefisch** (Alemania) dice que su delegación no considera que el tema del fraude comercial sea prioritario. La secretaría debería vigilar la situación y, en caso necesario, adoptar disposiciones para que se actualicen los indicadores.

15. El **Presidente** observa que hay acuerdo en que es necesario vigilar las novedades en el ámbito del fraude comercial y, en particular, promover la coordinación con la labor realizada por la UNODC. En cuanto a la propuesta de celebrar un coloquio, sugiere que la Comisión vuelva a examinar el tema en el período de sesiones siguiente.

16. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) propone que se autorice a la secretaría a organizar reuniones de expertos sobre el tema.

17. La **Sra. Sabo** (Canadá) cuestiona la conveniencia de que los escasos recursos de la secretaría se dediquen a ese tipo de trabajo. Si, a la luz de las actividades de vigilancia que desempeña, la secretaría considerase necesaria la adopción de nuevas medidas a ese respecto, la cuestión podría remitirse a la Comisión en su período de sesiones siguiente.

18. El **Sr. Rivera Mora** (El Salvador) dice que su delegación otorga gran importancia al tema del fraude comercial que, como lo demuestran las estadísticas, es un problema significativo. En consecuencia, apoyaría un análisis independiente de los mecanismos que se podrían aplicar para resolver el problema.

19. El **Sr. Chan Wah Teck** (Singapur) dice que su delegación respalda las opiniones expresadas por los representantes de Alemania y el Canadá. Los efectos del fraude en el comercio internacional no alcanzan una escala que corresponda al mandato de la CNUDMI de armonizar el derecho mercantil internacional.

20. El **Sr. Schoefisch** (Alemania) concuerda con las observaciones hechas por los representantes del Canadá y Singapur. El fraude comercial es básicamente una cuestión de derecho penal.

21. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que su delegación no está proponiendo que la secretaría utilice sus escasos recursos para tratar esa cuestión. Sin embargo, se debería autorizar a la secretaría a que dé cumplimiento a una posible decisión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas respecto de la cooperación entre la CNUDMI y la UNODC en la elaboración de una ley modelo sobre el robo de identidad.

22. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) asegura a la Comisión que, por el momento, la secretaría no tiene previsto dedicar recursos a proyectos como la redacción de una ley modelo. Un funcionario dedicará un tiempo muy reducido a vigilar las novedades en el ámbito del fraude comercial, también en el contexto de la UNODC. Si pareciera necesaria una labor más de fondo, la secretaría remitiría el asunto a la Comisión.

23. El **Presidente** dice que se han tenido en cuenta las preocupaciones del representante de los Estados Unidos. La cuestión del fraude comercial se volverá a examinar en el período de sesiones siguiente.

24. A continuación, invita a la secretaría a presentar el tema del derecho contractual internacional.

25. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que en el 45° período de sesiones de la Comisión, en 2012, la delegación de Suiza presentó una propuesta relativa a la labor en el ámbito del derecho contractual internacional. La Comisión pidió a la secretaría que organizara simposios y otras reuniones oficiosas para evaluar la necesidad de esa labor y que investigara, en colaboración con el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), la necesidad de actualizar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, de 1980. La secretaría no pudo organizar simposios ni otras reuniones debido a la falta de recursos. Sin embargo, asistió a reuniones sobre el tema celebradas en los Estados Unidos, una organizada por el Departamento de Estado y otra por la Universidad Villanova de Pensilvania. La secretaría seguirá evaluando la viabilidad de celebrar simposios u otro tipo de reuniones oficiosas sobre el derecho contractual internacional.

26. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) señala a la atención de los delegados la propuesta de los Estados Unidos que figura en el documento A/CN.9/789 sobre la organización por la CNUDMI de un coloquio para celebrar en 2015 el 35° aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. La Convención se considera uno de los tratados que ha tenido más éxito en la historia del derecho mercantil moderno. Ya cuenta con 79 Estados partes, y la organización de un coloquio para celebrar el aniversario probablemente daría lugar a un nuevo aumento de las ratificaciones. El orador señala que la CNUDMI copatrocinó la reunión sobre derecho contractual internacional celebrada en la Facultad de Derecho de Villanova en enero de 2013. Además, en febrero de 2013 se celebró en el Centro Regional para Asia y el Pacífico de la CNUDMI una reunión de expertos en derecho contractual. En consecuencia, la secretaría ha cumplido con la solicitud de organizar simposios y otras reuniones.

27. Su delegación no considera necesaria una iniciativa mundial sobre el derecho contractual internacional, pero está dispuesta a considerar la posibilidad de introducir reformas. En los períodos de sesiones de 2007 y 2010 la Comisión hizo suyos los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales del UNIDROIT, que son un complemento valioso de la Convención. El UNIDROIT

vigila constantemente los principios, con miras a aumentar su utilidad.

28. La **Sra. Sabo** (Canadá) dice que, según su delegación, no hay una necesidad demostrable de revisar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, sobre todo porque fue complementada efectivamente por la edición de 2010 de los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales del UNIDROIT. Expresando su apoyo a la propuesta de celebrar el 35º aniversario de la Convención, la oradora dice que la necesidad de revisarla se podría evaluar en esa ocasión.

29. El **Sr. Schoefisch** (Alemania) sugiere que la Comisión confirme la solicitud formulada a la secretaría en el período de sesiones anterior. Observa con agradecimiento que la secretaría ha señalado que seguirá evaluando la viabilidad de celebrar un simposio u otro tipo de reunión oficiosa sobre el derecho contractual internacional, y dice que le interesaría también conocer la opinión de la secretaría sobre la propuesta de celebrar en 2014 el 35º aniversario de la Convención.

30. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que sería importante no solo celebrar el aniversario de la Convención, sino también aprovechar la oportunidad para analizar ciertos asuntos que no se abordaron a fondo en ese instrumento. Como es un poco prematuro adoptar decisiones sobre la labor de la Comisión en 2015, tal vez sea preferible no fijar una fecha para el coloquio y autorizar a la secretaría a examinar la cuestión y evaluar la disponibilidad de los recursos necesarios.

31. El **Presidente** observa que la Comisión apoya la idea de organizar un coloquio para celebrar el 35º aniversario de la Convención. El coloquio no se referirá únicamente a la Convención, sino que también arrojará luz en ámbitos en que todavía no se ha logrado la armonización. Se autorizará a la secretaría a estudiar el asunto y a determinar la fecha más adecuada para el coloquio.

32. La **Sra. Sabo** (Canadá) recomienda que el coloquio se celebre durante uno de los períodos ordinarios de sesiones de la Comisión.

33. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) observa que, cuando en 2005 la CNUDMI celebró el 25º aniversario de la Convención, la Comisión examinó varios documentos relativos a distintos asuntos, así como los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales del UNIDROIT.

34. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que en el período de sesiones siguiente la secretaría presentará a la Comisión una propuesta detallada.

35. El **Presidente** invita a la secretaría a presentar el tema titulado “Microfinanciación: creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas”.

36. El **Sr. Lemay** (Secretaría) presenta el documento A/CN.9/780 y dice que el tema de las microfinanzas y la creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYME) figura en el programa de la Comisión desde su 42º período de sesiones, en 2009, cuando la Comisión pidió a la secretaría que preparara un estudio detallado que incluyera una evaluación de las cuestiones legales y reglamentarias que se planteaban en el ámbito de las microfinanzas. El estudio también debía comprender propuestas sobre la forma y naturaleza de un posible documento de referencia para los legisladores y los encargados de la formulación de políticas que indicara los elementos necesarios para establecer un marco jurídico propicio a las microfinanzas. En su 43º período de sesiones, la Comisión debatió el estudio y acordó que la secretaría convocaría un coloquio, con la participación de expertos de otras organizaciones, para examinar las cuestiones jurídicas y reglamentarias que correspondieran al mandato de la CNUDMI. El coloquio se celebró en enero de 2011. En su 44º período de sesiones, la Comisión decidió incluir las microfinanzas como tema de su labor futura y solicitó a la secretaría que preparara un estudio acerca de cuatro asuntos básicos y que distribuyera entre los Estados un cuestionario sobre sus experiencias en la creación de un marco legislativo y reglamentario para las microfinanzas y sobre los obstáculos encontrados. El estudio se presentó a la Comisión en su 45º período de sesiones, en 2012, y la Comisión convino en celebrar uno o varios coloquios sobre microfinanciación y otros temas conexos que se relacionaran con la creación de condiciones jurídicas propicias para las MIPYME.

37. Del 16 al 18 de enero de 2013 se celebró un coloquio al que asistieron expertos de gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado e instituciones académicas, y el informe resultante se publicó en el documento A/CN.9/780. En el coloquio hubo amplio consenso en que debería establecerse un grupo de trabajo a fin de abordar los aspectos jurídicos de las condiciones propicias para las MIPYME. La creación de esas condiciones correspondería al mandato principal de la Comisión de promover la coordinación y la cooperación en la esfera del comercio

internacional, incluido el comercio transfronterizo regional. Los participantes sugirieron asimismo que un instrumento flexible, como una guía legislativa o una ley modelo, ayudaría en la labor de armonización del sector e impulsaría reformas que alentarían aún más la participación de las microempresas en la economía.

38. El cuestionario distribuido entre los Estados en 2011 tenía nueve preguntas, algunas de carácter general y otras más específicas, sobre financiación garantizada, dinero electrónico, supervisión de las instituciones de microfinanciación y solución de controversias por transacciones de poca cuantía. Veintinueve Estados respondieron al cuestionario. Algunas de las respuestas se resumieron en el documento A/CN.9/780. La secretaría ha preparado también una larga compilación de observaciones, pero por falta de recursos para traducir el documento a los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, esa compilación se publicará oficiosamente, solo en inglés, en las páginas protegidas con contraseña del sitio web de la CNUDMI.

39. Muy pocos Estados han promulgado legislación sobre microfinanciación o microcréditos, y la evaluación de los efectos reguladores antes de iniciar el proceso legislativo parece ser la excepción más que la regla. Entre los principales retos señalados cabe mencionar la falta de formalización de las empresas; dificultades para crear conciencia acerca del sector de las microfinanzas; el hecho de que las entidades financieras superan la capacidad de supervisión de los reguladores; la existencia de marcos reguladores limitados y/o contradictorios; y dificultades para normalizar algunos de los conceptos principales de las microfinanzas. En los Estados que no han promulgado una legislación específica, las disposiciones generales que rigen las instituciones financieras se aplican también, en la mayoría de los casos, a las microfinanzas.

40. En cuanto a la financiación garantizada, la mayor parte de los Estados permiten a las MIPYME usar todo tipo de bienes como garantía y no hacen diferencias en razón del tamaño de la empresa. Algunos no autorizan el uso de bienes futuros o elementos fijos para garantizar el crédito. La mayoría de los Estados cuentan con un sistema de registro y otros lo están estableciendo. Algunos Estados permiten la ejecución de las garantías reales sin la participación de los tribunales, mientras que otros exigen un mandamiento de ejecución, normalmente mediante una decisión judicial. Varios Estados no regulan en su jurisdicción el dinero electrónico. Otros aplican disposiciones jurídicas especiales y no reconocen ese dinero como ahorro. En la mayoría de los Estados el dinero

electrónico no está contemplado en los regímenes de seguro de los depósitos.

41. Como norma, las instituciones de microfinanciación son supervisadas por los mismos organismos que vigilan los mercados financieros, y los reglamentos que se les aplican son los mismos que rigen para las instituciones financieras y los agentes de crédito. En algunos Estados se han designado organismos específicos para la supervisión de las instituciones de microfinanciación. En todos los Estados se prevé la confidencialidad, normalmente en la legislación aplicable a los servicios financieros o la protección de los consumidores. En general, se exige a las instituciones financieras que den a conocer a sus clientes los términos y condiciones de sus servicios.

42. Respecto de la solución de controversias de poca cuantía, la mayoría de los Estados indicaron que las controversias financieras se podían resolver ante tribunales judiciales o de arbitraje. En algunos Estados se han establecido instituciones especializadas para la resolución de las controversias dimanantes de reclamaciones financieras y relativas a contratos con consumidores. En algunos casos los consumidores pueden presentar denuncias ante el banco central o un defensor del pueblo. En general, los Estados no aplican métodos especiales para la solución de controversias relacionadas con las microfinanzas.

43. Los Estados no parecen tener una opinión uniforme acerca de la necesidad de promulgar legislación específica sobre las microfinanzas. Entre los ámbitos en que se recomendó que se estableciera legislación se incluyen la oferta de capital para inversiones en microfinanciación; la calidad de los productos y servicios ofrecidos; los criterios para el otorgamiento de licencias especializadas; la definición de microcrédito; las directrices para la inscripción y el otorgamiento de licencias a las instituciones de microfinanciación; los procesos de supervisión y recuperación; la revelación de información; la garantía de los préstamos de microcrédito; las salvaguardias para prestatarios de bajos ingresos; y los mecanismos extrajudiciales de solución de controversias.

44. El Sr. Vélez (Colombia) dice que la Comisión, en su 45º período de sesiones, convino en celebrar uno o más coloquios sobre las microfinanzas y la creación de condiciones jurídicas propicias para las MIPYME. La secretaría resumió las conclusiones del coloquio celebrado en enero de 2013 en el documento A/CN.9/780. Entre otras cosas, se recomendó que se estableciera un grupo de trabajo para examinar los aspectos jurídicos de la creación de esas condiciones propicias. También se destacó que esa labor de creación de condiciones propicias correspondería

al mandato principal de la Comisión de promover la coordinación y cooperación en la esfera del comercio internacional, incluido el comercio transfronterizo regional. Las MIPYME necesitan un marco jurídico reconocido internacionalmente para poder operar de manera eficaz en todo el mundo. En consecuencia, el orador propone que en el año siguiente se reserven dos semanas para que un grupo de trabajo se reúna y examine las microfinanzas y otros asuntos conexos. La propuesta figura en el documento A/CN.9/790 y fue copatrocinada por El Salvador, Filipinas, Kenya y Uganda. Sería la primera vez en la historia de la CNUDMI que una propuesta de países en desarrollo dé lugar al establecimiento de un grupo de trabajo.

45. El **Presidente** solicita al representante de Colombia que formule observaciones sobre los criterios aplicables para la priorización de los temas. Las cuestiones básicas que se deben dilucidar son si la formalización de las MIPYME tiene probabilidades de generar consenso en un grupo de trabajo y un aumento del comercio internacional; si otros organismos internacionales, como el Grupo Banco Mundial, ya se están ocupando del tema; y si el tema está suficientemente claro en los aspectos técnicos y en cuanto a las cuestiones de política que se han de abordar.

46. El **Sr. Vélez** (Colombia) dice que el sector no estructurado, que opera al margen de la ley, representa una proporción importante de muchas economías emergentes. Por ejemplo, puede suponer hasta el 50% de la actividad económica en Colombia y en muchos otros países de América Latina. Se estima que en el mundo la mitad de la fuerza de trabajo está empleada en el sector no estructurado y, según datos del Banco Mundial, el valor de las actividades comerciales realizadas por ese sector asciende a unos 10 billones de dólares de los Estados Unidos. En consecuencia, las actividades tendientes a formalizar las MIPYME promoverían el estado de derecho. Sin embargo, los problemas que se deben abordar son sumamente complejos. Las razones que han llevado a las empresas a operar en el sector no estructurado comprenden la carga tributaria, la excesiva regulación del sector estructurado, el deterioro de la calidad de la administración pública y la dinámica del sector estructurado. En la mayoría de los Estados el problema no es la falta de legislación, sino la mala calidad de las leyes que existen. El objetivo que se ha de perseguir es el fomento de un marco jurídico simple y flexible que no obstaculice la formalización. El marco debe estar relacionado con los distintos componentes del ciclo de vida de una empresa y podría consistir, por ejemplo, en una ley modelo relativa a la creación e inscripción de las MIPYME. Se deberían prever mecanismos de microfinanciación y servicios

bancarios simplificados, mecanismos de solución de controversias por vías alternativas y regímenes de la insolvencia simplificados. No cabe duda de que las actividades en este ámbito corresponden al mandato de la CNUDMI de promover la modernización y armonización del derecho mercantil internacional.

47. El **Sr. Maradiaga** (Honduras) encomia la sinopsis de los problemas relativos a las microfinanzas que se ofrece en el documento A/CN.9/780, que ilustra claramente los efectos negativos en las economías emergentes de la situación económica actual. También comparte las opiniones expresadas por el representante de Colombia y hace suya la propuesta de elaborar un instrumento jurídico para abordar esos problemas. En Honduras se ha promulgado legislación sobre las microfinanzas y las MIPYME, pero no hay consenso sobre la forma en que se debe aplicar. En consecuencia, la preparación de un instrumento normativo por la CNUDMI sería de gran ayuda.

48. El **Sr. Schoefisch** (Alemania) observa con sorpresa que solo 29 Estados respondieron al cuestionario de la secretaría y que la mayoría de esos Estados no han promulgado legislación específica sobre las microfinanzas. Por esa razón, apoya la propuesta de comenzar a trabajar en esa esfera, prestando especial atención a los aspectos del comercio internacional.

49. El **Sr. Bellenger** (Francia) dice que, si bien Francia apoya la propuesta, el alcance y la complejidad del tema suscitan cierta preocupación. Tal vez sea conveniente centrar inicialmente la atención en el derecho de las empresas.

50. El **Sr. Fruhmann** (Austria) dice que no queda claro si el tema que se debate se refiere a las microfinanzas y el microcrédito o a los problemas relativos a la creación de condiciones jurídicas propicias para las MIPYME. El alcance de este último tema, por ejemplo en sus aspectos sociales, es mucho más amplio que el del primero. La claridad es esencial si se ha de asignar un mandato a un grupo de trabajo. Habida cuenta de la escasez de recursos, una segunda cuestión que se plantea es si la formalización es en sí deseable, si satisface una necesidad económica y si tendría un efecto beneficioso en el comercio internacional. Los problemas jurídicos que afrontan las microempresas son distintos de los de las pequeñas y medianas empresas. Se presume también que la formalización dará lugar a la reanudación del crecimiento económico. A ese respecto, el orador destaca la tendencia registrada en la Unión Europea, en las condiciones económicas actuales, a introducir cláusulas de escape y exenciones a los regímenes jurídicos en favor de las empresas pequeñas y

medianas a fin de aumentar sus oportunidades de desarrollo.

51. La **Sra. Phongsathit** (Tailandia) respalda la propuesta hecha por el representante de Colombia. Hace hincapié en la importancia de que las microempresas gocen de condiciones jurídicas propicias, especialmente en los países en desarrollo, donde un gran número de MIPYME participan regularmente en el comercio transfronterizo. La Comisión también tiene que seguir estudiando el acceso de las MIPYME al crédito y el marco jurídico conexo. Su delegación considera que el resultado tendría efectos beneficiosos en el comercio internacional.

52. El **Presidente** observa que se ha expresado amplio apoyo a la propuesta presentada por el representante de Colombia y copatrocinada por otras cuatro delegaciones. El alcance del tema es muy amplio, ya que comprende todo el ciclo comercial y una gran variedad de cuestiones. Por lo tanto, la Comisión tal vez desee centrar su atención en una sola esfera, pues de esa manera sería más fácil responder a las preguntas consiguientes, relativas, por ejemplo, a si la formalización es deseable y viable, y si hay cuestiones de política pública en juego. A su juicio, la simplificación de la constitución en sociedad es la primera cuestión que se debería examinar. En caso de establecerse un grupo de trabajo, este tendría que familiarizarse con los estudios pertinentes, por ejemplo, sobre la eficacia de la constitución en sociedad. También sería necesario investigar si la constitución en sociedad simplificada tendría el mismo efecto en las microempresas y en las pequeñas y medianas empresas. Además, el grupo de trabajo debería tener presentes las diferentes circunstancias en distintas partes del mundo.

53. El **Sr. Chan Wah Teck** (Singapur) dice que las microfinanzas no es una esfera en que la CNUDMI deba adoptar medidas urgentes. Sin embargo, el debate en curso se refiere a una propuesta completamente diferente, a saber, la creación de condiciones propicias para las MIPYME. El vínculo entre los dos componentes del tema es que las MIPYME necesitan microfinanciación.

54. En muchos casos, la magnitud del sector no estructurado de la economía impone límites al desarrollo y tiene consecuencias negativas en el comercio internacional. En consecuencia, si bien el tema parece estar comprendido en el mandato de la CNUDMI, abarca un gran número de cuestiones. El objetivo básico es modernizar la legislación interna con miras a facilitar el desarrollo económico y social nacional. Se plantea el interrogante de si ese objetivo no se podría alcanzar más eficazmente por conducto de otro organismo internacional, dentro o fuera del sistema de las Naciones Unidas. Además, los mandatos

de algunos grupos de trabajo de la CNUDMI ya existentes abarcan ciertos aspectos del tema. Por ejemplo, los pagos móviles están incluidos en el programa del Grupo de Trabajo IV, sobre comercio electrónico, y el programa del Grupo de Trabajo II, sobre arbitraje y conciliación, comprende una forma simplificada de solución de controversias. Por otra parte, aun si se reformara la legislación interna a fin de crear condiciones propicias para las MIPYME, esas medidas no tendrían efectos extraterritoriales a menos que la CNUDMI elaborase una convención encaminada a promover la extraterritorialidad y, por ende, el comercio internacional. Sin embargo, el orador duda de que ese sea un resultado viable. En resumen, su delegación no se opone al establecimiento de un grupo de trabajo, pero estima que esa medida puede ser prematura, ya que todavía no se ha realizado la labor preparatoria de definición del mandato preciso.

55. La **Sra. Fernández Sobarzo** (Observadora de Chile) expresa su firme apoyo a la propuesta hecha por el representante de Colombia. El coloquio celebrado en enero de 2013 puso en evidencia la importancia y el alcance del tema, especialmente para los países en desarrollo. Si al comienzo se estrechara el ámbito del estudio, el grupo de trabajo podría elaborar un instrumento jurídico dinámico y moderno que facilitaría el funcionamiento a la luz del día de empresas que actualmente operan en el sector no estructurado.

Se suspende la sesión a las 16.10 horas y se reanuda a las 16.35 horas.

56. La **Sra. Matos** (Observadora de la República Dominicana) apoya la propuesta hecha por el representante de Colombia, que será de ayuda a los países en desarrollo que cuentan actualmente con un gran número de MIPYME.

57. El **Sr. Arosemena** (Panamá) apoya la propuesta, formulada tanto por el representante de Colombia como en el coloquio de enero de 2013, de establecer un grupo de trabajo sobre la creación de condiciones jurídicas propicias para las MIPYME.

58. El **Sr. Rodríguez** (Suiza) dice que la importancia de las microfinanzas para el desarrollo económico en todo el mundo queda demostrada por el número de órganos multilaterales que se ocupan del tema. Entre los criterios uniformes que se deben aplicar al establecer prioridades en la labor futura de la Comisión figuran los efectos que un tema tiene en el comercio internacional, la claridad con respecto a su alcance y la existencia de documentación pertinente. Otro criterio es evitar la duplicación de tareas. Debe aclararse la necesidad de promulgar legislación

supranacional sobre la gran variedad de cuestiones que abarca este tema. Sería útil tener una visión general de los trabajos realizados por otros órganos, como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, y escuchar su opinión sobre la posible coordinación de su labor con la de la CNUDMI.

59. En algunas legislaciones se ofrece a las empresas la posibilidad de elegir libremente la condición de entidad informal. La conducta de esos agentes no se considera ilegal, siempre que paguen impuestos y las demás contribuciones. Además, algunos estudios han indicado que un alto grado de formalización de las empresas no redundaría necesariamente en un mayor crecimiento económico.

60. La delegación de Suiza no está recomendando que los criterios de priorización se apliquen estrictamente a la propuesta de Colombia en el período de sesiones en curso. Es partidaria de que, a mediano plazo, se trabaje en ciertos aspectos de ese tema, como la constitución de sociedades, y opina que se podría solicitar también a grupos de trabajo ya existentes que se centren en cuestiones de interés para las MIPYME, como la solución de controversias simplificada y los procedimientos de insolvencia.

61. La **Sra. Mlosovicova** (República Bolivariana de Venezuela) expresa su apoyo a la propuesta de Colombia de establecer un grupo de trabajo sobre la creación de condiciones jurídicas propicias para las MIPYME. El grupo de trabajo no debería centrarse exclusivamente en las MIPYME, sino que debería también abordar la disponibilidad de microfinanciación para otros tipos de asociaciones y grupos.

62. El **Sr. Rivera Mora** (El Salvador) dice que los Estados que participan en la CNUDMI y otros foros están en general preparados para elaborar marcos jurídicos que regulen las empresas grandes y transnacionales. Sin embargo, cuando se trata de las MIPYME, se observa una tendencia a restar importancia a los posibles beneficios públicos y privados. Dirigiéndose en particular a los Estados miembros de la Unión Europea, el orador dice que la creación de un grupo de trabajo para promover la formalización del sector no estructurado sería muy beneficiosa para los países en desarrollo, incluidos los miembros futuros de la Unión Europea, no solo en los aspectos económicos, sino también en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones financieras internacionales. En consecuencia, su delegación apoya firmemente la propuesta del representante de Colombia.

63. La **Sra. Sabo** (Canadá) reitera la posición de su delegación en el sentido de que no se cuenta con un

proyecto bien definido en la esfera de las microfinanzas. Sin embargo, el Canadá apoyó la propuesta hecha por la delegación de Colombia en el 45º período de sesiones de la Comisión, sobre un proyecto relativo a la simplificación de la constitución e inscripción de sociedades. La cuestión de si el proyecto se debe someter a un grupo de trabajo es un tema aparte. Sería útil contar con aportaciones por escrito de la secretaría sobre la labor en ese ámbito y los aspectos del tema que habría que abordar.

64. En cuanto a la propuesta hecha por Colombia en el período de sesiones en curso, sobre la creación de condiciones jurídicas propicias para las MIPYME, algunos de los temas, como han señalado otros oradores, ya figuran en el programa de grupos de trabajo existentes. En consecuencia, podría ser suficiente que la Comisión invitara a esos grupos a examinar si podrían ajustar su labor para que tenga en cuenta las necesidades de las MIPYME.

65. La **Sra. Gibbons** (Ecuador) apoya la propuesta del representante de Colombia debido a la importante función que desempeñan las MIPYME en las economías de los países en desarrollo. A ese respecto, destaca la conveniencia de que se promuevan normas flexibles.

66. El **Sr. Zhang** Chenyang (China) apoya la propuesta del representante de Colombia e insta a la Comisión a centrar su labor futura en la creación de condiciones propicias para las MIPYME. En el coloquio celebrado en enero de 2013 se abordaron muchos aspectos técnicos del tema, pero también es necesario investigar los aspectos legislativos.

67. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que la secretaría preparará documentos de trabajo sobre el tema si se lo pide la Comisión. Sin embargo, los documentos no estarían listos para ser examinados por un grupo de trabajo hasta el segundo trimestre de 2014.

68. El **Sr. Ivančo** (Observador de la República Checa) apoya la propuesta de abordar el tema de las MIPYME. Sin embargo, su delegación propone que inicialmente la labor se centre en la simplificación de la constitución de sociedades.

69. El **Presidente** interpreta que la propuesta que se examina es un llamamiento a que la Comisión asigne recursos sustanciales a actividades encaminadas a atender las preocupaciones de los países en desarrollo, y asegura a las delegaciones interesadas que ese llamamiento ha sido escuchado.

Se levanta la sesión a las 17.00 horas.

**Acta resumida de la 978ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
Viena, el martes 23 de julio de 2013, a las 9.30 horas**

[A/CN.9/SR.978]

Presidente: Sr. Schöll (Suiza)

Se declara abierta la sesión a las 9.50 horas.

Labor prevista y posible labor futura, entre otras cosas en los ámbitos del arbitraje y la conciliación, el fraude comercial, el comercio electrónico, el régimen de la insolvencia, el derecho contractual internacional, las microfinanzas, la solución de controversias en línea, la contratación pública y el desarrollo de infraestructuras, incluida la colaboración entre el sector público y el sector privado, y las garantías reales (continuación) (A/CN.9/752 y Add.1, 774, 779, 780, 789 y 790)

1. El **Presidente**, haciendo referencia al debate celebrado en la sesión anterior de la Comisión respecto del tema “Microfinanciación: creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas”, sugiere añadir el texto siguiente al proyecto de informe:

“Tras deliberar, la Comisión acordó que se añadiera a su programa de trabajo la labor destinada a reducir los obstáculos jurídicos que afectaban a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en todo su ciclo de vida, sobre todo a las de los países en desarrollo.

También convino en que al iniciar esa labor se prestara especial atención a las cuestiones jurídicas relacionadas con la constitución de sociedades, y que la secretaría preparara la documentación necesaria para convocar sin tardanza un grupo de trabajo.

Asimismo, la Comisión acordó que el grupo de trabajo incluyera en sus informes sobre la marcha de los trabajos a la Comisión: i) información o datos empíricos que demostraran qué relación guardaba su trabajo con el desarrollo sostenible y la financiación inclusiva, o que los afectaban; y ii) información sobre la forma en que su trabajo complementaba el de otras organizaciones internacionales e intergubernamentales que tenían un mandato en esas esferas.”

El Presidente invita al Secretario de la Comisión a que indique de qué manera se podría distribuir la labor

propuesta y cuánto tiempo llevaría sentar las bases para establecer un grupo de trabajo sobre el tema.

2. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que normalmente se encomienda a los grupos de trabajo que preparen un texto, y no que presenten a la Comisión informes sobre la situación jurídica en distintos países o sobre un tema en particular. Está claro que el grupo de trabajo propuesto deberá tener en cuenta la información y los datos a que se hace referencia en el texto leído por el Presidente. Sin embargo, tal vez sea preferible no limitar el mandato a investigaciones.

3. La secretaría preparará documentos en que se examinará la experiencia de los países en desarrollo en la esfera de la simplificación de la constitución en sociedad de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYME), teniendo en cuenta los aspectos jurídicos de la constitución de sociedades en otros países. Necesitará cierto tiempo para realizar estudios comparativos y celebrar reuniones de grupos de expertos. Estima que los documentos necesarios se podrían presentar antes de fines de 2013 y que el grupo de trabajo se podría convocar en el segundo trimestre de 2014.

4. La **Sra. Sabo** (Canadá) propone que el mandato de reunión de información que se encomienda al grupo de trabajo en el texto leído por el Presidente se asigne en cambio a la secretaría.

5. La oradora propone además que se añadan las palabras “la simplificación de” antes de “la constitución de sociedades” en la oración que comienza con “También convino en”.

6. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) propone modificar la oración que acaba de mencionar la representante del Canadá para que diga: “prestar especial atención a la elaboración de uno o varios instrumentos jurídicos relativos a la simplificación de la constitución de sociedades y su inscripción”. Propone además agregar la oración siguiente: “La labor también deberá incluir los elementos de condiciones jurídicas propicias señalados en el coloquio y detallados en el documento de la secretaría y el documento presentado por la delegación de Colombia”. De esta manera la labor abarcará la solución de controversias por vías alternativas, la banca móvil y

dinero electrónico, acceso al crédito, operaciones garantizadas e insolvencia.

7. El orador conviene con la representante del Canadá en que la secretaría puede encargarse de las tareas de reunión de información mencionadas al final del texto leído por el Presidente. Sin embargo, señala que en los informes de la secretaría sobre los dos coloquios ya se incluye una gran cantidad de información pertinente.

8. Respecto de los criterios de priorización, considera que es probable que en un grupo de trabajo se llegue a un consenso respecto del tema de la simplificación de la constitución de sociedades y la inscripción registral de empresas. Ello también daría lugar ciertamente al aumento del comercio internacional, ya que aproximadamente el 50% de las empresas de muchos países en desarrollo operan en el sector no estructurado y, en consecuencia, no pueden competir en el comercio internacional. En el documento A/CN.9/780, relativo a las microfinanzas, se cita al Banco Mundial, que ha determinado que las economías con sistemas modernos de registro comercial crecen más rápidamente, promueven una mayor iniciativa empresarial y productividad, crean empleo, impulsan la certeza jurídica y atraen corrientes más grandes de inversión extranjera directas. En el coloquio de enero de 2013 también se destacó que la creación de condiciones jurídicas propicias para las MIPYME se ajustaría al mandato principal de la Comisión de promover la coordinación y cooperación en la esfera del comercio internacional, incluido el comercio transfronterizo regional.

9. Respecto de la labor realizada en ese ámbito por otros organismos internacionales, en ambos coloquios se concluyó que esos organismos no participaban en la creación de condiciones jurídicas propicias para las MIPYME porque no se ocupaban del sector no estructurado. En consecuencia, es imperativo que la CNUDMI se ocupe del tema, ya que los Estados copatrocinantes y que expresaron su apoyo a la labor futura en esta esfera representan a todas las regiones del mundo.

10. Otro criterio de priorización es si el tema es suficientemente claro desde la perspectiva técnica y de cuestiones de política que habrá de comprender. En su opinión, se reúnen esas condiciones. La delegación de Colombia propuso que se elaborase una ley modelo sobre simplificación de la constitución de sociedades y la inscripción registral de empresas. Entre otras propuestas relacionadas con el tema cabe mencionar las notas sobre cómo se podría organizar la solución de controversias por vías alternativa en el ámbito de las microfinanzas; una guía

de mejores prácticas en el ámbito de los pagos móviles; y leyes modelo sobre acceso al crédito y la insolvencia.

11. Su delegación no se opone a la propuesta de que otros grupos de trabajo aborden aspectos del tema comprendidos en su esfera de competencia. La Comisión deberá aclarar este asunto cuando asigne las prioridades, por ejemplo a los grupos de trabajo sobre derecho de la insolvencia y sobre arbitraje y conciliación, y deberá coordinar entre los distintos grupos de trabajo las cuestiones relacionadas con las MIPYME.

12. El **Sr. Adensamer** (Austria) dice que su delegación apoya el texto propuesto por el Presidente. Sin embargo, propone sustituir “labor destinada a reducir los obstáculos jurídicos” por “labor sobre derecho mercantil internacional con miras a reducir los obstáculos jurídicos”.

13. La **Sra. Laborte-Cuevas** (Filipinas) dice que la creación de condiciones propicias para las MIPYME se ajusta al mandato de la Comisión de promover la coordinación y cooperación en la esfera del comercio internacional, incluido el comercio transfronterizo regional. Filipinas está de acuerdo en que se encomiende a la secretaría la preparación de documentos de información antes de convocar en 2014 un grupo de trabajo a fin de examinar la simplificación de la constitución en sociedad de las MIPYME.

14. El **Sr. Chan Wah Teck** (Singapur) entiende que la Comisión todavía está celebrando un debate general sobre las cuestiones planteadas por Colombia en el documento A/CN.9/790 y que en el proyecto de informe se recogerán todas las demás cuestiones sobre las que se llegue a un consenso. El título del tema es “Microfinanciación: creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas”, pero el orador propone que en el informe se indique que la Comisión ya no se está ocupando de la cuestión de las microfinanzas. Si bien muchos de los oradores han mencionado las conclusiones de los dos coloquios, señala que en ambos la atención se centró en las microfinanzas. En consecuencia, no es sorprendente que los representantes de otros organismos internacionales que asistieron a los coloquios hayan demostrado escaso interés en crear condiciones jurídicas propicias para las MIPYME.

15. Singapur no se opone a la creación de un grupo de trabajo. Sin embargo, el mandato del grupo de trabajo deberá definirse claramente mediante una cuidadosa labor preparatoria de la secretaría, con aportaciones de representantes de organismos de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas dedicadas a la creación de condiciones jurídicas propicias para las pequeñas y

medianas empresas. En la actualidad otros grupos de trabajo de la CNUDMI están examinando muchas cuestiones conexas. El orador destaca que aunque esos grupos no tienen un mandato exclusivo en esas esferas, han acumulado considerable experiencia al respecto. En consecuencia, si el nuevo grupo de trabajo propuesto tiene que abordar el tema de la solución de controversias por vías alternativas, se encontrará en una situación muy desventajosa a menos que pueda aprovechar la experiencia de los miembros del grupo de trabajo sobre arbitraje y conciliación. La secretaría deberá tener en cuenta este aspecto cuando realice su labor preparatoria.

16. **El Presidente** invita a que se formulen más observaciones respecto de si la Comisión debe decidir suprimir la referencia a la “microfinanciación”.

17. El **Sr. Schoefisch** (Alemania) expresa su apoyo a la creación del grupo de trabajo propuesto, al que se deberá encomendar un mandato claramente definido. Conviene en que el primer párrafo del texto propuesto por el Presidente debe referirse al derecho mercantil internacional y que en el segundo párrafo deben agregarse las palabras “la simplificación de”.

18. En su experiencia, el término “microfinanciación” es algo engañoso. En consecuencia, conviene con el representante de Singapur en que la Comisión debe aclarar que ya no está contemplando las microfinanzas, sino la creación de condiciones jurídicas propicias para las MIPYME.

19. En cuanto a la declaración del representante de los Estados Unidos, el orador advierte que no se debe sobrecargar al grupo de trabajo con una gran diversidad de temas. Inicialmente deberá centrar su atención en un tema único y luego, cuando la Comisión decida que ha llegado el momento oportuno, pasar a considerar otras cuestiones.

20. El **Sr. Maradiaga** (Honduras) dice que, en su opinión, no hay una diferencia de fondo entre microfinanciación y creación de condiciones jurídicas propicias para las MIPYME. Se trata de una simple cuestión terminológica. La Comisión debe adoptar un criterio constructivo. Se encomendará a la secretaría la tarea fundamental de compilar la información necesaria e investigar los vínculos con la labor de otros organismos internacionales. Luego deberá organizarse un coloquio a fin de debatir las conclusiones.

21. **El Presidente** dice que “creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas” es un título excesivamente largo para un grupo de trabajo. Sugiere como alternativa “marco para las MIPYME”.

22. El **Sr. Anwar** (Indonesia) destaca la importante función que desempeñan las MIPYME tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo y expresa su apoyo a la creación de un grupo de trabajo. En 2012 las MIPYME representaron en Indonesia el 59,08% del producto interno bruto y el país ha registrado una tasa de crecimiento económico de aproximadamente el 6%. Además, en 2012 las MIPYME dieron empleo a unos 107 millones de personas. La legislación regulatoria de las MIPYME se promulgó en 1995.

23. La **Sra. Malaguti** (Italia) expresa su apoyo a la propuesta de establecer un grupo de trabajo y al proyecto de resumen del Presidente, en su forma enmendada. Italia ha destacado permanentemente que su apoyo dependerá de que se establezca un vínculo entre el comercio internacional y las medidas encaminadas a reducir los obstáculos jurídicos que afrontan las MIPYME.

24. El **Sr. Rodriguez** (Suiza) también expresa su apoyo a la versión enmendada del resumen del Presidente.

25. Es importante aprovechar la experiencia acumulada por los distintos grupos de trabajo y solicitarles que aborden distintos aspectos del tema que se examina. Si todos esos aspectos se encomendaran a un solo grupo de trabajo, se necesitaría un plazo extremadamente largo para los debates. También se podría prever la coordinación de las tareas de más de un grupo de trabajo.

26. **El Presidente** invita a la Comisión a formular observaciones acerca de si el siguiente resumen del debate y la decisión son aceptables. La creación de un grupo de trabajo sobre el tema de las MIPYME, que se reuniría por primera vez en el segundo trimestre de 2014 ha recibido amplio apoyo. Entre tanto, la secretaría se encargaría de las tareas preparatorias necesarias. Señala tres enmiendas al resumen propuesto: que en el primer párrafo se sustituya “labor destinada a reducir los obstáculos jurídicos” por “labor sobre derecho mercantil internacional con miras a reducir los obstáculos jurídicos”; que en el segundo párrafo se añadan las palabras “la simplificación de” antes de “la constitución de sociedades”; y que en el tercer párrafo se indique que “la Comisión acordó que la secretaría emprendiera la siguiente labor preparatoria” y que después de “organizaciones intergubernamentales” se añadan las palabras “de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas”.

27. El **Sr. Vélez** (Colombia) dice que su delegación considera aceptables el resumen y la decisión propuestos. Entiende que cuando el grupo de trabajo se reúna durante una semana en el segundo trimestre de 2014 debatirá un proyecto de ley modelo sobre la simplificación de la

constitución de sociedades. En el informe se deberá aclarar que para la preparación de esa ley modelo se necesitarán como mínimo dos semanas.

28. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) reasegura al representante de Colombia que no se espera que el grupo de trabajo prepare una ley modelo en un solo período de sesiones. Rara vez una tarea de esta naturaleza se finaliza en menos de dos años.

29. El **Sr. Cabeiro Quintana** (Observador de Cuba) expresa su apoyo al establecimiento de un grupo de trabajo sobre la creación de condiciones jurídicas propicias para las MIPYME. Su delegación conviene con la recomendación hecha en la sesión anterior por el representante de la República Bolivariana de Venezuela de que el grupo de trabajo no centre su atención exclusivamente en las MIPYME, sino que también se ocupe de la disponibilidad de microfinanciación para otros tipos de asociaciones y grupos.

30. El **Sr. Nogués** (Paraguay) dice que su delegación desea copatrocinar la propuesta de creación de un grupo de trabajo. En el Paraguay hay unas 300.000 MIPYME que generan una gran cantidad de empleo. Sin embargo, a la mayoría de estas empresas se les niega acceso a los servicios financieros.

31. El **Sr. Bellenger** (Francia) dice que en el informe se debe mencionar la propuesta de que la Comisión se abstenga de utilizar el término “microfinanciación” en los mandatos que encomiende a los grupos de trabajo.

32. El **Presidente** entiende que la Comisión desea eliminar el término “microfinanciación”, reconociendo al mismo tiempo que en los debates relativos a las microfinanzas se aclararon otros aspectos del tema que se abordarán en el futuro.

33. El representante de Singapur recomendó que no se estableciera un grupo de trabajo hasta que la secretaría hubiera completado las tareas preparatorias. Esa recomendación fue apoyada por los representantes de Alemania, Austria y Suiza. El Presidente pregunta si esas delegaciones se opondrían a una decisión de la Comisión, adoptada en el actual período de sesiones, de establecer un grupo de trabajo que se reuniría en el segundo trimestre de 2014.

34. El **Sr. Chan Wah Teck** (Singapur) dice que su delegación no se opone a una decisión de esa naturaleza. Sin embargo, si la secretaría no finaliza su labor preparatoria antes del segundo trimestre de 2014, el grupo de trabajo no estará en condiciones de comenzar sus deliberaciones. El representante de Honduras propuso la

celebración de un coloquio. El orador sugiere que este se celebre apenas la secretaría finalice su labor.

35. Una de las tareas fundamentales encomendadas a la secretaría es la elaboración de una definición de microempresa y pequeña y mediana empresa.

36. El orador propone que en el segundo párrafo del resumen del Presidente se haga referencia a las investigaciones que habrá de realizar la secretaría respecto de la labor pertinente de otros organismos de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas.

37. La **Sra. Sabo** (Canadá) dice que, si bien en principio conviene en que un coloquio podría cumplir una finalidad útil, le preocupa que tal vez la Comisión esté sobrecargando a la secretaría. Quizá sea preferible autorizar a la secretaría a celebrar consultas con expertos acerca de distintos aspectos de su labor preparatoria.

38. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) conviene en que sería preferible que la secretaría se reuniera con expertos en lugar de organizar un coloquio.

39. En su declaración anterior, el orador propuso que en el resumen del Presidente se hiciera referencia a una lista de los elementos constitutivos de las condiciones jurídicas propicias. Esta lista ayudaría a otros grupos de trabajo a evaluar la pertinencia del tema para sus propios mandatos antes de que se reuniera el nuevo grupo de trabajo. Por ejemplo, hay cierta confusión respecto del mandato específico del Grupo de Trabajo V sobre el Régimen de la Insolvencia. Sugiere que los regímenes de insolvencia simplificados, mencionados en el documento A/CN.9/790 presentado por Colombia, tal vez constituyan un tema adecuado.

40. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que la experiencia ha demostrado que no es particularmente fácil promover la cooperación entre distintos grupos de trabajo. También duda de que la publicación de una lista general de temas relacionados con las MIPYME impulse a algunos de los grupos de trabajo existentes a asumir uno de esos temas. Además, advierte que la ampliación del mandato del nuevo grupo de trabajo tal vez desestabilice a los grupos de trabajo existentes.

41. La **Sra. Talero** (Colombia) conviene con la representante del Canadá en que la propuesta de celebrar un coloquio quizá sobrecargue a la secretaría, especialmente en un momento en que los recursos presupuestarios son escasos. También conviene en que el grupo de trabajo centre inicialmente su atención en la simplificación de la constitución de sociedades.

42. El **Sr. Maradiaga** (Honduras) retira su propuesta de celebrar un coloquio.

43. El **Presidente** concluye que existe un amplio acuerdo respecto de la propuesta de Colombia de establecer un grupo de trabajo sobre el marco de las MIPYME, que se reuniría por primera vez en el segundo trimestre de 2014. Entretanto, la secretaría se encargaría de la labor preparatoria, de conformidad con la versión enmendada del resumen del Presidente.

44. *Así queda acordado.*

Se suspende la sesión a las 11.30 horas y se reanuda a las 11.50 horas.

45. El **Presidente** invita a la secretaría a presentar el tema titulado “Contratación pública y esferas conexas, incluida la colaboración entre el sector público y el privado”.

46. La **Sra. Nicholas** (secretaría) dice que, en su 45º período de sesiones de 2012, la Comisión convino en que la secretaría organizaría un coloquio sobre la colaboración entre el sector público y el privado con miras a determinar si la Comisión debía trabajar en esa esfera. En tal sentido, señala a la atención la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada, aprobada por la Comisión en 2000, y las Disposiciones Legales Modelo sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada, aprobadas en 2003. El propósito del coloquio celebrado en mayo de 2013 fue evaluar si las recomendaciones de la Guía Legislativa y las Disposiciones Legales Modelo seguían constituyendo una guía adecuada para esos proyectos de infraestructura y si el mercado de la colaboración entre el sector público y el privado estaba suficientemente desarrollado. En el coloquio hubo amplio consenso acerca de la importancia de esta colaboración como tema de desarrollo y como apoyo a las inversiones extranjeras directas y el desarrollo sostenible.

47. Respecto de los criterios de priorización, la oradora señala el informe sobre el coloquio que figura en el documento A/CN.9/779. El primer criterio es si es probable que el tema dé lugar a consenso en el grupo de trabajo. El concepto de “colaboración entre el sector público y el privado” se ha definido y regulado en varios Estados a partir de 2005. En los estudios recientes se ha observado que se han adoptado criterios sumamente diferentes para la regulación de la colaboración entre el sector público y el privado, a pesar de que hay muchos textos sobre el tema en los planos regional e internacional. En consecuencia, no se cuenta con un estándar de aplicación universal que puedan usar los Estados. Por

ejemplo, en los textos de la CNUDMI no se incluyen las concesiones de recursos naturales, que sí se han incorporado a otros textos internacionales pertinentes. También hay un alto grado de confusión respecto de la terminología, el contenido de la legislación relativa a la colaboración entre el sector público y el privado y sus relaciones con otras leyes. Por ello, en el coloquio se concluyó que no había una necesidad urgente de abordar los resultados caóticos y sin coordinación que se observan en la esfera legislativa. Los textos vigentes de la CNUDMI no pueden cumplir esta función.

48. El alcance de la posible labor de la CNUDMI sobre la colaboración público-privada se establece en los párrafos 36 a 45 del documento A/CN.9/779. En el coloquio se expresó fuerte apoyo a la noción de una ley modelo sobre la colaboración público-privada y se aprobó una guía similar a la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Contratación Pública que la Comisión aprobó en 2012. Sin embargo, se reconoció que, de no ser posible la publicación de una serie amplia de orientaciones de política, tal vez fuera preferible una guía legislativa. En el coloquio no se abordó la cuestión de si la elaboración de un texto jurídico mejoraría el derecho mercantil internacional. Tampoco se definió el alcance preciso de la labor que debía preverse. Por ejemplo, entre los participantes hubo algunas discrepancias acerca de la complejidad de los trabajos que tal vez fueran necesarios a fin de armonizar y sintetizar los textos vigentes de la CNUDMI y otros instrumentos pertinentes. Sin embargo, la Comisión Económica para Europa indicó que prestaría su apoyo pleno a la labor legislativa de la CNUDMI y la aprovecharía para impulsar sus actividades de creación de capacidad. La secretaría no encontró ámbitos de duplicación de tareas con otros organismos internacionales.

49. Se puede argumentar que el tema está en condiciones de ser remitido a un grupo de trabajo. Sin embargo, en los párrafos 69 y 70 del documento A/CN.9/779 se afirma que se necesitan más trabajos preparatorios para definir un mandato más preciso. Las personas dedicadas actualmente a la colaboración público-privada indicaron que se necesitaba con urgencia un texto que contuviera una serie de temas claramente definidos y limitados. Si bien los expertos reconocen la utilidad de los textos de la CNUDMI, no se los utiliza ampliamente en el ámbito del desarrollo internacional. En el coloquio se concluyó que los textos futuros se deberían elaborar en el contexto de un grupo de trabajo. Los comentarios figuran en los párrafos 82 y 83 del informe.

50. Teniendo presente la importancia de determinar cuáles son los elementos fundamentales que deben incluirse en una ley modelo y la importancia de comprender las técnicas pertinentes que se aplican en la actualidad, tal vez la Comisión desee considerar la posibilidad de que la investigación documental de la secretaría se complemente mediante consultas con expertos y otras personas dedicadas al tema, especialmente en los países en desarrollo, con el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo. En el coloquio no se recomendó que el tema se remitiera de inmediato a un grupo de trabajo. Algunos participantes recomendaron que en primer término se determinara qué partes de la Guía Legislativa era necesario actualizar y que se examinara en el contexto de coloquios o grupos de expertos la posibilidad de elaborar una ley modelo. En el 47º período de sesiones de 2014 podría presentarse a la Comisión una propuesta firme. A fin de adoptar medidas en ese sentido la CNUDMI necesitaría recursos para servicios de apoyo a conferencias para una semana como máximo.

51. El **Sr. Bellenger** (Francia) señala la importante función de la colaboración público-privada en el desarrollo sostenible y la gran necesidad de contar en los países en desarrollo con una infraestructura para dicha colaboración en un momento en que los fondos públicos son escasos y la asistencia para el desarrollo ha disminuido. Se trata de un tema delicado y complejo que debe confiarse a un grupo de trabajo una vez finalizada la labor preparatoria definida por la secretaría, que podría incluir la celebración de coloquios.

52. El **Sr. Fruhmann** (Austria) dice que la colaboración público-privada es un tema importante, tanto para los países desarrollados como los países en desarrollo, y que satisface los criterios de priorización. Su delegación apoya el establecimiento de un grupo de trabajo después de la labor preparatoria de la secretaría, incluida la celebración de coloquios. El orador pregunta cuándo se podrían celebrar esos coloquios.

53. La **Sra. Nicholas** (secretaría) dice que la secretaría prevé adoptar un criterio flexible y transparente y tratar de lograr la participación más amplia posible, por ejemplo, mediante la organización de reuniones de grupos de expertos en Europa y América del Norte y la celebración de coloquios en otras regiones. Los bancos regionales de desarrollo y el Banco Mundial han expresado su apoyo a ese criterio.

54. El **Sr. Dennis** (Estados Unidos de América) dice que, en una sesión anterior, el representante de Singapur destacó el párrafo 20 del documento A/CN.9/779 sobre la colaboración público-privada, en donde se señalaba que los

instrumentos de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada no eran muy conocidos y habían resultado de utilidad limitada para legisladores y reguladores.

55. La ley modelo propuesta ya está virtualmente terminada y, en el documento A/CN.9/789, los Estados Unidos sugirieron que se la ultimara en una reunión de expertos y no en un coloquio, y que en 2014 se la presentara a un grupo de trabajo para su aprobación. Su delegación advierte que no debería ampliarse su alcance ni prolongarse los debates.

56. La **Sra. Sabo** (Canadá) dice que su delegación no está convencida de que la ley modelo sea el instrumento adecuado. Los instrumentos de proyectos de infraestructura con financiación privada elaborados previamente por la CNUDMI siguen siendo sumamente pertinentes. Sin embargo, conviene con la propuesta de que la secretaría realice trabajos preparatorios con la asistencia de expertos. Cuando presente sus conclusiones en 2014, la Comisión podrá decidir si conviene elaborar una guía o una ley modelo.

57. La **Sra. Nicholas** (secretaría) dice que en el coloquio celebrado en mayo de 2013 se examinó si el texto jurídico propuesto ya estaba virtualmente completo y solo necesitaba actualizarse. Se concluyó que todavía se necesitaban más trabajos y que no podría completarse exclusivamente mediante investigaciones de la secretaría. También se subrayó la necesidad de adoptar un criterio inclusivo en las consultas con expertos mediante mecanismos concebidos para promover el multilingüismo y la transparencia. Se ha propuesto celebrar un coloquio a fin de satisfacer esos requisitos.

58. La **Sra. Whyte** (Reino Unido) expresa su apoyo a las observaciones de la representante del Canadá.

59. La **Sra. Malaguti** (Italia) dice que los grupos de expertos que consulte la secretaría deben incluir representantes del sector público.

60. **El Presidente** dice que se dispone de recursos para cinco días de reuniones de grupos de expertos en distintas partes del mundo, en aras de la transparencia y con miras a obtener la mayor diversidad posible de opiniones sobre el tema. Una posible razón de la aplicación limitada de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre Proyectos de Infraestructura con Financiación Privada es que no se celebraron consultas amplias respecto de ese instrumento.

61. El **Sr. Chan Wah Teck** (Singapur), hablando en calidad de ex-Presidente del período de sesiones de la Comisión de 2000, en el que se aprobó la Guía Legislativa

de la CNUDMI, dice que durante las prolongadas deliberaciones en ningún momento se dio a entender que el texto tuviera algún tipo de deficiencia ni que las consultas previas no hubieran sido suficientemente amplias.

62. El **Sr. Fruhmann** (Austria) dice que el instrumento propuesto debería responder a las necesidades prácticas y no ser indebidamente complejo.

63. **El Presidente** observa que la Comisión está de acuerdo en que la secretaría continúe su labor sobre la colaboración público-privada y la organización de consultas con expertos. Habida cuenta de la escasez de recursos, la secretaría adoptará un criterio flexible respecto de si debe convocarse un coloquio con el apoyo de los bancos regionales de desarrollo.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

**Acta resumida de la 979ª sesión, celebrada en el Centro Internacional de Viena,
Viena, el martes 23 de julio de 2013, a las 14.00 horas**

[A/CN.9/SR.979]

Presidente: Sr. Schöll (Suiza)

Se declara abierta la sesión a las 14.10 horas.

Labor prevista y posible labor futura, entre otras cosas en los ámbitos del arbitraje y la conciliación, el fraude comercial, el comercio electrónico, el régimen de la insolvencia, el derecho contractual internacional, las microfinanzas, la solución de controversias en línea, la contratación pública y el desarrollo de infraestructuras, incluida la colaboración entre el sector público y el sector privado, y las garantías reales (continuación) (A/CN.9/752 y Add.1, 774 y 789; A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.8)

1. El **Presidente** dice que se han confirmado los mandatos del Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación), del Grupo de Trabajo III (Solución de Controversias en Línea) y del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) y que a los tres grupos se les han asignado dos sesiones de grupo de trabajo.

2. Invita a la secretaría a presentar el tema relativo al régimen de la insolvencia.

3. La **Sra. Clift** (Secretaría) hace referencia al resumen del debate de la Comisión celebrado la semana anterior, contenido en el proyecto de informe (A/CN.9/XLVI/CRP.1/Add.8). Algunas de las propuestas se debatieron informalmente durante el período transcurrido desde entonces.

4. La Comisión convino en que el mandato confiado al Grupo de Trabajo V no se había cumplido plenamente y que no quedaba claro de qué forma debería proceder el Grupo de Trabajo con respecto a las tareas pendientes. Se propuso que, con sujeción a la disponibilidad de recursos, se celebrara un coloquio en diciembre de 2013. Se propuso asimismo que el coloquio se realizara en el contexto de una reunión del Grupo de Trabajo. En el coloquio se examinarían los asuntos relacionados con los grupos de sociedades y los temas para la labor futura, que podían incluir las cuestiones relativas a la insolvencia planteadas por las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes). En la primavera de 2014, el Grupo de Trabajo continuaría su labor sobre los asuntos relacionados con los grupos de sociedades y tal vez también las cuestiones relativas a las pymes. La Comisión decidiría cómo proseguir sobre la base del informe del Grupo de

Trabajo y, de ser necesario, formularía un mandato adicional relativo a las pymes.

5. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya en general las propuestas esbozadas por la secretaría, incluida la de celebrar un coloquio, seguido de una reunión del Grupo de Trabajo, en diciembre de 2013. Los expertos que asistan al coloquio deberían presentar sus opiniones sobre las cuestiones de la insolvencia relacionadas con las pymes, y debería darse un mandato al Grupo de Trabajo para que examine esas cuestiones cuando se reúna en abril de 2014. El grupo de trabajo sobre las pymes recién establecido puede determinar las cuestiones de política pública y obtener aclaración sobre los aspectos de la insolvencia conexos, así como asesoramiento, por parte del Grupo de Trabajo V, sobre otros asuntos que se estime conveniente abordar.

6. El Grupo de Trabajo debatió largamente el tema del centro de los principales intereses (CPI) en el contexto de los grupos de sociedades. Un coloquio sería de gran utilidad para determinar la labor que ha de realizarse en esa esfera y brindar asesoramiento sobre la conveniencia o no de preparar una guía legislativa o ley modelo. Desde luego, los miembros del Grupo de Trabajo deberían decidir si desean emprender un proyecto de esa índole.

7. El **Sr. Rodríguez** (Suiza) y el **Sr. Maradiaga** (Honduras) expresan su apoyo respecto del enfoque recomendado por el representante de los Estados Unidos.

8. La **Sra. Talero** (Colombia) también se declara partidaria de las propuestas formuladas por el representante de los Estados Unidos. La insolvencia es motivo de gran preocupación para las pymes, que requieren procedimientos más ágiles y flexibles y menos costosos. El Grupo de Trabajo V cuenta con pericia suficiente para abordar el tema y la coordinación en materia de políticas con el nuevo grupo encargado de las pymes puede ser muy fructífera.

9. La **Sra. Sabo** (Canadá) apoya las propuestas esbozadas por la secretaría. En cuanto a las observaciones del representante de los Estados Unidos, entiende que el propósito del coloquio sería ayudar al Grupo de Trabajo V a fin de aclarar de qué forma debería abordar las cuestiones relacionadas con los grupos de sociedades y generar

nuevas ideas. Sin embargo, sus conclusiones no serían determinantes a ese respecto. Esa decisión corresponde a la Comisión sobre la base de la evaluación que haga el Grupo de Trabajo.

10. El **Sr. Schoefisch** (Alemania) hace suyas las propuestas formuladas por el representante de los Estados Unidos. Concuera con la representante del Canadá en que el objetivo del coloquio es identificar los temas que podría abordar el Grupo de Trabajo V y la Comisión decidiría cuáles considera apropiados.

11. El **Sr. Bellenger** (Francia) también subraya la necesidad de distinguir entre los procesos de reflexión y la puesta en práctica. Está de acuerdo con las observaciones hechas a este respecto por los representantes del Canadá y Alemania.

12. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) lee la siguiente propuesta de mandato para el Grupo de Trabajo V relativo a las pymes: “Tras un debate, la Comisión acordó que el Grupo de Trabajo V emprenda la labor relativa a la insolvencia en el contexto de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas con arreglo a un mandato adicional, en coordinación con el nuevo grupo de trabajo”.

13. El **Sr. Schoefisch** (Alemania) entiende que en un primer momento los participantes en el coloquio y el Grupo de Trabajo V deberían examinar los posibles temas futuros.

14. La **Sra. Sabo** (Canadá) dice que la propuesta del representante de los Estados Unidos implica que se daría al Grupo de Trabajo V un doble mandato de continuar el examen de los temas relativos a los grupos de sociedades y abordar un nuevo tema cuyo examen podría requerir varios períodos de sesiones. Su delegación opina que la Comisión debería examinar los diversos elementos del tema de las pymes en 2014. Sería útil que entre tanto los grupos de trabajo proporcionaran a la Comisión información a fin de ayudarla a adoptar una decisión sobre esos elementos.

15. El **Presidente** dice que parece haber amplio apoyo a la asignación de la primera parte del período de sesiones de cinco días previsto en diciembre de 2013 a la celebración de un coloquio en el que se examinaría la parte pendiente del mandato del Grupo de Trabajo y se generaría nuevas ideas. Asimismo, se ha expresado amplio apoyo a la idea de que, a su debido tiempo, el Grupo de Trabajo examine la insolvencia en el contexto de las pymes. Sin embargo, existen opiniones divergentes sobre el momento en que debería hacerlo. Sugiere que el nuevo grupo de trabajo relativo a las pymes, que se reunirá en la primavera de 2014, determine las cuestiones básicas que han de

abordarse en una situación de insolvencia y las presente a la Comisión para que esta adopte una decisión al respecto. En respuesta a una pregunta del representante de Alemania, el orador confirma que si el Grupo de Trabajo V examina esas cuestiones, estas no serían tratadas por ningún otro grupo de trabajo.

16. La **Sra. Sabo** (Canadá) dice que es esencial determinar si la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia aborda la cuestión de la insolvencia en relación con las pymes.

17. El **Presidente** dice que el Grupo de Trabajo puede examinar esa cuestión y estudiar formas de realzar la utilidad de la Guía Legislativa desde la perspectiva de las pymes.

18. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) dice que, como es obvio, las ideas sobre todo nuevo proyecto que surjan del coloquio no se pondrían en práctica sin la aprobación previa de la Comisión. Su delegación simplemente sugiere que se autorice al Grupo de Trabajo a examinar la insolvencia en el contexto de las pymes durante el período anterior al próximo período de sesiones de la Comisión. Se trataría de examinar el tema únicamente desde un punto de vista técnico en coordinación con el nuevo grupo de trabajo, el cual se encargaría de determinar las cuestiones de política y definir el alcance de su labor.

19. La **Sra. Clift** (Secretaría) propone el siguiente proyecto de texto para el informe: “Tras un debate, la Comisión acordó que se pida al Grupo de Trabajo V que examine los aspectos de la insolvencia relativos a las pymes, incluida la cuestión de si la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia proporciona suficientes soluciones al respecto y, de no ser así, determine la labor que aún se requiere en este sentido, con miras a presentar un informe a la Comisión en 2014.”

20. El **Presidente** dice que en el proyecto de informe también se señalaría que se asignarían cinco días hábiles en diciembre de 2013 para celebrar un coloquio y una reunión del Grupo de Trabajo a fin de estudiar la cuestión pendiente del mandato, a saber, el centro de los principales intereses en el contexto de los grupos de sociedades, y examinar otras posibles cuestiones.

21. La **Sra. Whyte** (Reino Unido) apoya las propuestas formuladas por la secretaría y el Presidente.

22. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) propone que se añada que las decisiones de política se reservarían al nuevo grupo de trabajo sobre las pymes. Los

otros grupos de trabajo podrían entonces brindar asesoramiento técnico.

23. El **Sr. Chan Wah Teck** (Singapur) dice que las consecuencias prácticas de la dicotomía entre consideraciones de política y consideraciones técnicas no son claras. Por regla general, los grupos de trabajo se reúnen para cumplir un determinado mandato y tienen la obligación de examinar todas las cuestiones de política y técnicas relacionadas con ese mandato.

24. El **Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) expresa reservas con respecto al establecimiento de una jerarquía entre los grupos de trabajo. Sería la primera vez que la Comisión asigna a un grupo de trabajo el mandato de elaborar políticas generales y coordinar las actividades de otro grupo de trabajo. La responsabilidad de la formulación de políticas incumbe a la Comisión. El procedimiento propuesto es, en su opinión, innecesariamente complejo. Si simplemente se trata de garantizar la coordinación entre los grupos de trabajo, la secretaría puede encargarse de velar por que existan la comunicación y sinergia necesarias.

25. El **Sr. Bellenger** (Francia) y el **Sr. Schoefisch** (Alemania) hacen suya la sugerencia de la secretaría.

26. El **Sr. Redmond** (Estados Unidos de América) dice que su delegación también apoyaría esa sugerencia siempre y cuando el nuevo grupo de trabajo se centre en las cuestiones de política relativas a las pymes y el Grupo de Trabajo V en las cuestiones técnicas.

27. La **Sra. Sabo** (Canadá) dice que la Comisión tratará esa cuestión en el momento de aprobar su informe.

28. El **Presidente** observa que existe un amplio consenso sobre el procedimiento de la Comisión con respecto al tema de la insolvencia.

29. La **Comisión** da por terminado su examen del tema 16 del programa, relativo a la labor futura.

Se suspende la sesión a las 14.55 horas y se reanuda a las 15.00 horas.

Función que desempeña la CNUDMI en el fomento del estado de derecho a nivel nacional e internacional

30. El **Presidente** invita a la secretaría a presentar el tema del programa.

31. La **Sra. Musayeva** (Secretaría) dice que el tema relativo al fomento del estado de derecho figura en el programa de la Comisión desde su 41º período de sesiones, celebrado en 2008, atendiendo a la invitación formulada

por la Asamblea General a la Comisión a que, en sus informes a la Asamblea, examinara la función de la Comisión en el fomento del estado de derecho. En sus períodos de sesiones 41º a 45º, la Comisión expresó su convicción, en sus informes anuales a la Asamblea General, de que la promoción del estado de derecho en las relaciones comerciales debería formar parte integrante del programa más amplio de las Naciones Unidas en materia de promoción del estado de derecho en los planos nacional e internacional. La Asamblea General hizo suya esa opinión.

32. En su 43º período de sesiones, la Comisión destacó la importancia de entablar un diálogo periódico con el Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, por conducto de la Dependencia sobre el Estado de Derecho, y de mantenerse al corriente de los progresos realizados en la integración de la labor de la CNUDMI en las actividades conjuntas de las Naciones Unidas relativas al estado de derecho. Con esa finalidad, pidió a la Secretaría que organizara sesiones informativas bianuales a cargo de la Dependencia sobre el Estado de Derecho que coincidieran con la celebración del período de sesiones de la Comisión en Nueva York. La primera sesión informativa se celebró durante el 45º período de sesiones de la Comisión en 2012 y la siguiente está prevista para 2014. En la sesión informativa de 2012, se informó a la Comisión de los progresos realizados con respecto a la sensibilización sobre la labor de la CNUDMI y los preparativos para una reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho. La Comisión propuso medios de asegurar que determinados aspectos de su labor quedaran debidamente reflejados en la reunión de alto nivel y en su documento final.

33. La Comisión no tiene ante sí ningún informe escrito para su examen durante el actual período de sesiones. No obstante, la oradora señala a la atención de la Comisión la resolución 67/97 de la Asamblea General, relativa al estado de derecho en los planos nacional e internacional. En el párrafo 17, la Asamblea General decidió que en el sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea, en 2013, la Sexta Comisión centrara sus debates en el subtema “El estado de derecho y el arreglo pacífico de controversias internacionales”. Dado que la Comisión tal vez desee asimismo centrar la atención en ese subtema en sus observaciones a la Asamblea General, la secretaría invitó a participar en una mesa redonda a expertos en esferas conexas de la labor de la CNUDMI, a saber, el arbitraje y la conciliación y la solución de controversias en línea.

34. En su resolución 67/97, la Asamblea General decidió asimismo que en el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, en 2014, la Sexta Comisión centrara la atención en el subtema “Puesta en común de las prácticas nacionales de los Estados para el fortalecimiento del estado de derecho mediante el acceso a la justicia”. La Comisión tal vez desee adoptar la decisión de centrar sus debates en ese mismo subtema en su próximo período de sesiones.

35. **El Presidente** invita al profesor Hrvoje Sikirić de Croacia, que presidió el último período de sesiones de la Comisión, a que informe acerca de la aplicación de las decisiones pertinentes adoptadas por la Comisión en su 45º período de sesiones y de sus instrucciones relativas a la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho.

36. **El Sr. Sikirić** (Croacia) dice que en el 45º período de la Comisión hubo consenso con respecto a que el Presidente de la CNUDMI pronunciara un discurso ante la Reunión de Alto Nivel y que en el documento final de esa reunión se reconociese la contribución realizada por la CNUDMI al fomento del estado de derecho en el ámbito económico, que era vital para el fomento del estado de derecho en un contexto más amplio. El orador dice que la Comisión le solicitó, en su calidad de Presidente, que transmitiera las opiniones expresadas por la Comisión en su informe sobre el 45º período de sesiones a la Oficina del Presidente de la Asamblea General. Además de su diálogo con esa Oficina, el orador dice que se invitó a la CNUDMI a presentar sus opiniones sobre el fortalecimiento del estado de derecho a nivel nacional e internacional a la Reunión de Alto Nivel celebrada el 24 de septiembre de 2012.

37. Como cuestión clave, el orador mencionó que el estado de derecho guardaba relación no solo con problemas de derecho internacional público, derechos humanos, derecho penal y justicia de transición, sino también con el reconocimiento y el respeto de los derechos de propiedad y los contratos, y con las medidas destinadas a garantizar la seguridad jurídica necesaria para promover la actividad empresarial, la inversión y la creación de empleo, así como la capacidad de los Estados para movilizar recursos en apoyo de los aspectos fundamentales del estado de derecho, como las garantías procesales y la infraestructura judicial y jurídica, incluida la disponibilidad de abogados y jueces debidamente capacitados. En su intervención ante la Reunión, el orador dio ejemplos del amplio efecto de la labor de la CNUDMI a ese respecto sobre la base de las observaciones formuladas por los profesionales durante los debates

celebrados en la Comisión. Se refirió asimismo a las medidas recomendadas por la CNUDMI en el sentido de que los países interesados podían alcanzar una capacidad sostenida para llevar a cabo reformas del derecho comercial, de ser necesario con asistencia de la comunidad internacional.

38. Señaló que la Declaración de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional contenía dos párrafos en los que la opinión de la CNUDMI sobre el fomento del estado de derecho en el ámbito económico figuraba como un elemento esencial del fomento del estado de derecho en un contexto más amplio. En el párrafo 7 se reconocía que el estado de derecho y el desarrollo estaban estrechamente relacionados y se reforzaban mutuamente y que el progreso del estado de derecho en los planos nacional e internacional era esencial para el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible. Se instó a reflexionar sobre esa interrelación en el contexto de la agenda para el desarrollo después de 2015. En el párrafo 8 se reconoció la importancia de los marcos jurídicos justos, estables y previsibles para crear desarrollo, crecimiento económico y empleo inclusivos, sostenibles y equitativos, generar inversiones y facilitar la actividad empresarial y se encomió la labor realizada por la CNUDMI para modernizar y armonizar el derecho mercantil internacional. De este modo, la Reunión de Alto Nivel permitió aumentar la sensibilización con respecto al fomento del estado de derecho en el ámbito económico, la importancia de atender a esas necesidades y la función constructiva de la Comisión a esos efectos.

39. **El Sr. Sorieul** (Secretario de la Comisión) dice que la CNUDMI fue invitada a participar en una reunión en junio de 2013 en el contexto del debate temático de la Asamblea General sobre el tema “Iniciativa empresarial para el desarrollo”. El Sr. Sikirić, en su calidad de Presidente de la CNUDMI, transmitió el mensaje de que una sociedad no podía desarrollarse a menos que reconociera y observara efectivamente las relaciones jurídicas. Era necesario contar con un entorno habilitador, leyes, instituciones, conocimientos especializados y prácticas, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo.

40. En junio de 2013 se celebró asimismo, con el patrocinio de la Comisión de Consolidación de la Paz y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una conferencia de un día de duración sobre la posible función del sector privado en la asistencia a los países frágiles a fin de ayudarlos a salir de los conflictos. El Presidente de la CNUDMI actuó de moderador de una mesa redonda

en la que se examinaron medios y arbitrios para resolver los desafíos que enfrentaban los entornos frágiles en un contexto de consolidación de la paz.

41. La Dependencia sobre el Estado de Derecho pidió a la secretaría que preparara una nota orientativa del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la promoción del estado de derecho en las relaciones comerciales. La Dependencia está examinando el texto preparado por la secretaría, que se basa esencialmente en las decisiones adoptadas por la Comisión desde 2008. Su finalidad es fortalecer de forma sostenida la capacidad de los Estados para promover el estado de derecho en las relaciones comerciales, de ser necesario con la asistencia de la comunidad internacional; y reforzar la capacidad de las Naciones Unidas para atender con eficacia las necesidades de los Estados a ese respecto. El texto puede ser utilizado con fines diversos, como en los contextos de la prevención de conflictos, la reconstrucción posterior a los conflictos y el desarrollo.

42. En la Declaración aprobada al final de la Reunión de Alto Nivel sobre el estado de derecho se instó a examinar la relación entre el estado de derecho y el desarrollo en el contexto de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015. Una actividad especial prevista en el contexto de la Asamblea General el 25 de septiembre de 2013 centrará la atención en ese tema. La agenda para el desarrollo después de 2015 tiene por objeto suplementar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y brindará la oportunidad de examinar la experiencia adquirida a ese respecto. Aún no queda claro si la CNUDMI estará invitada a presentar sus opiniones.

43. El orador dice que también se están celebrando deliberaciones en el marco del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo Sostenible. El Grupo de Trabajo se reunió cuatro veces en 2013 y programó otras cuatro reuniones durante el período comprendido hasta febrero de 2014. Tiene previsto examinar el crecimiento económico, la creación de infraestructura, el estado de derecho y la gobernanza. Se adoptarán medidas para velar por que las contribuciones pertinentes de la CNUDMI se tengan en cuenta.

44. La Comisión tal vez desee tomar nota de la pertinencia de su labor con respecto a la formulación, en todo el sistema de las Naciones Unidas, de aspectos de la agenda internacional para el desarrollo después de 2015 que guarden relación con el estado de derecho. Tal vez desee asimismo pedir al Presidente y la secretaría que tomen medidas apropiadas para asegurar que no se pase

por alto el papel de la CNUDMI en la promoción del estado de derecho y el desarrollo sostenible.

45. La **Sra. Sabo** (Canadá) hace suyas las propuestas de la secretaría con respecto a la labor futura.

46. **El Presidente** invita al primer ponente, Mark McNeill, asociado de Shearman & Sterling's International Arbitration Group, en París y especialista en inversiones internacionales y arbitraje comercial, a hacer uso de la palabra. Anteriormente, el Sr. McNeill fue funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde estaba encargado de los litigios entre inversionistas y Estados y de la redacción de los capítulos relativos a la inversión de los acuerdos de libre comercio.

47. El **Sr. McNeill** (ponente) dice que hablará sobre el arbitraje comercial como marco jurídico neutro para la solución de controversias y como herramienta para la prevención de conflictos, centrando principalmente la atención en las industrias de extracción. Hará referencia asimismo a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York).

48. Uno de los primeros ejemplos de arbitraje internacional como medio de prevención y solución de controversias fue el Tratado Jay de 1794 entre los Estados Unidos y el Reino de Gran Bretaña. Dado que varias controversias habían quedado sin resolver durante los 10 años transcurridos desde la guerra de independencia, persistía el riesgo de que surgiera un nuevo conflicto. Las comisiones creadas con arreglo a este Tratado para solucionar esas controversias tenían algunas características que hoy en día son reconocidas como hitos del arbitraje internacional. Sus deliberaciones demostraron la utilidad de aplicar un procedimiento especial adaptado a cada controversia. Un enfoque similar es el adoptado, por ejemplo, en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Una vez constituido el tribunal arbitral, este tiene poderes inherentes para decidir, en consulta con las partes, sobre el plazo en el que se dictará el laudo arbitral, el número y el orden de los alegatos y la manera en que el tribunal obtendrá pruebas y otros aspectos de los procedimientos. Otra característica básica del arbitraje con arreglo al Tratado Jay es el establecimiento de un foro neutral y desnacionalizado. Ninguna parte está obligada a litigar en los tribunales de la otra parte, y las comisiones están exentas de interferencia gubernamental y tienen derecho a adoptar decisiones en el ámbito de su propia jurisdicción. De modo análogo, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional ha demostrado ser un instrumento eficaz para garantizar la independencia y desnacionalización del arbitraje internacional. Su

artículo 5, por ejemplo, consagra el principio de que los tribunales no deben interferir en los procedimientos de arbitraje internacional.

49. Desde 1958, la Convención de Nueva York, que ha sido ratificada por 148 Estados, proporciona un conjunto común de normas para el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales internacionales. Exige a los tribunales nacionales de los Estados contratantes que ejecuten laudos dictados por otros Estados contratantes a menos que sean incompatibles con la política pública o no sean ejecutables por alguna de las razones limitadas previstas en el artículo V. En un sitio web relacionado con la Convención figura una lista de más de mil decisiones pertinentes adoptadas por tribunales de jurisdicciones tanto de derecho civil como de derecho consuetudinario de distintas partes del mundo. El acceso a esa fuente por los tribunales debería contribuir a una mejor interpretación, coherencia y previsibilidad judiciales.

50. Con frecuencia, las actividades laborales en las industrias extractivas de los países en desarrollo se realizan en virtud de un acuerdo internacional entre una empresa multilateral y un organismo estatal. Esos acuerdos suelen entrañar inversiones a largo plazo que vinculan a agentes privados y públicos cuyos objetivos son a veces divergentes. Por lo general, el país productor necesita los recursos financieros y la pericia técnica de que dispone la empresa multinacional pero al mismo tiempo, como es natural, desea mantener soberanía sobre sus recursos naturales y desarrollar su propia tecnología. A largo plazo, el inversionista enfrenta riesgos comerciales, legales y políticos, dado que el Estado anfitrión podría cambiar de actitud con respecto a la inversión extranjera. Cuando surgen controversias, ninguna de las partes desea resolverlas en los tribunales de la otra parte. Por consiguiente, la práctica habitual suele ser que en los acuerdos pertinentes se incluyan cláusulas sobre arbitraje internacional. Las empresas multilaterales también tratan de celebrar tratados favorables en materia de inversión.

51. El arbitraje internacional privado o arbitraje basado en tratados ha sido uno de los medios más eficaces de resolver controversias transfronterizas relacionadas con inversiones y recursos naturales. Con todo, se plantea la cuestión de saber si ese tipo de arbitraje promueve el estado de derecho y ayuda a prevenir conflictos futuros en países que están luchando contra la pobreza y otras crisis. En el caso de procedimientos de arbitraje entre Estados, podría concluirse que el arbitraje internacional probablemente puede contribuir a resolver los conflictos, incluidas las controversias territoriales, en circunstancias favorables. Sin embargo, las partes deben tener confianza

en el proceso, estar decididas a resolver el diferendo y estar dispuestas a perder, lo que no suele ser el caso cuando el motivo de litigio se considera de vital importancia nacional.

52. Al celebrar un tratado internacional sobre inversión, se exige a algunos Estados que armonicen su régimen de inversión y otras leyes con las normas internacionales. Por otra parte, podría aducirse que el arbitraje internacional reduce la posibilidad de que surjan conflictos entre Estados al obviar la necesidad de una confrontación directa entre los Estados en nombre de sus ciudadanos agraviados. La disponibilidad de un mecanismo fiable para proteger las inversiones y resolver las reclamaciones tiende a aumentar la cantidad de capitales que los inversionistas están dispuestos a arriesgar en el extranjero, especialmente en países en desarrollo donde los tribunales podrían no ser del todo fiables. Además, el creciente recurso al arbitraje ha redundado en general en una mayor claridad con respecto a las normas legales aplicables a las inversiones.

53. Por otra parte, el arbitraje internacional en las industrias extractivas a veces ha tenido como consecuencia una reacción inversa, sobre todo en países de América Latina como el Ecuador. El arbitraje internacional también puede ocasionalmente imponer una carga indeseada para los Estados que se encuentran en situaciones posteriores a conflictos o luchan por recuperarse de una crisis nacional. Asimismo, en ciertos casos, los procedimientos de arbitraje relacionados con recursos estatales se consideran confidenciales y se ocultan a los ciudadanos que tienen intereses creados en la disposición de recursos públicos. La concertación de tratos comerciales secretos entre empresas multilaterales y funcionarios de gobierno puede fomentar la corrupción y crear disensión entre el público. Por tanto, el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado es de importancia fundamental, especialmente en las industrias extractivas.

54. En general, los instrumentos de la CNUDMI mencionados brindan un fuerte marco jurídico para la solución pacífica de controversias, lo que es sumamente importante en el volátil entorno de la inversión transfronteriza en las industrias extractivas. A menudo los inversionistas no tienen confianza en los sistemas judiciales de los países en desarrollo y de los Estados que están saliendo de una situación de conflicto. Por ello, el marco que brindan los instrumentos de la CNUDMI bien puede ser el único medio eficaz para atraer los fondos de inversión que se requieren para el desarrollo sostenible y la creación de capacidad.

55. La **Sra. Knieper** (Secretaría) dice que Myanmar y la República Democrática del Congo ratificaron recientemente la Convención de Nueva York, de manera que son ahora 150 los Estados partes. Además, el Iraq está estudiando la posibilidad de ratificar esa Convención.

56. **El Presidente** invita al ponente Daniel Magraw a hacer uso de la palabra. El Sr. Magraw es Presidente Emérito del Center for International Environmental Law (CIEL) y en esa calidad asistió como observador a las reuniones del Grupo de Trabajo II relacionadas con el Reglamento sobre la Transparencia. Ha sido también Consejero Jurídico General Asociado y Director de la Oficina de Derecho Internacional del Medio Ambiente del Organismo de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos.

57. El **Sr. Magraw** (ponente) dice que examinará el tema de la transparencia en el contexto del arbitraje entre inversionistas y Estados. Una cuestión inicial que hay que plantear es la definición de “estado de derecho”. Las Naciones Unidas lo han definido en el documento del Consejo de Seguridad S/2004/616 de la forma siguiente:

“un principio de gobierno según el cual, todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.”

El orador pone de relieve la necesidad de transparencia procesal y legal, que son conceptos fundamentales para las comunidades de empresarios e inversionistas. Ello crea certeza y previsibilidad jurídicas y contribuye a la equidad en la aplicación de la ley y permite evitar la arbitrariedad.

58. La transparencia guarda relación asimismo con la rendición de cuentas. Requiere que la conducta de los particulares, las organizaciones y las instituciones se den a conocer a los diversos sectores de la sociedad. Por ejemplo, en la comunidad empresarial, esto incluye las leyes sobre garantías que requieren la divulgación de las operaciones comerciales relacionadas con bienes materiales, lo que constituye un disuasivo para la corrupción. La divulgación de información sobre, por

ejemplo, la aplicación de leyes contra la contaminación ambiental puede utilizarse para evaluar si las leyes son cumplidas de forma equitativa. A nivel internacional, es vital tener acceso a la información sobre la aplicación de la ley, el grado de independencia con el que se determina el cumplimiento de la ley y el respeto de las normas de derechos humanos. Una herramienta importante a ese respecto son los informes paralelos presentados por organizaciones de la sociedad civil al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De hecho, existe ya el derecho humano de acceso a la información, basado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

59. Las controversias entre inversionistas y Estados son claramente una cuestión de interés público. Pueden entrañar un importante volumen de fondos en términos del producto interno bruto del país en cuestión y frecuentemente se relacionan con recursos naturales vitales. Pueden menoscabar la salud de la economía nacional y poner en peligro las normas ambientales que constituyen prerrogativas soberanas. El resultado de las causas abiertas hasta la fecha, que invariablemente incluyen alegatos de violación del derecho internacional por el país anfitrión, se utiliza para elaborar un corpus de derecho internacional. Por consiguiente, es vital difundir ampliamente esos resultados. Lamentablemente, el actual sistema aplicable a las controversias entre inversionistas y Estados es muy deficiente en términos de transparencia. De ello se desprende la relevancia del nuevo Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia, que ha sido el producto de más de tres años de intensas negociaciones. El Reglamento es preciso y equilibrado y abarca prácticamente todos los aspectos del arbitraje entre inversionistas y Estados sobre la base de tratados. No obstante, se plantea la interrogante de si ese Reglamento se aplicaría en la práctica, pues el tipo de presión que impondría en aras de conseguir la transparencia asusta a muchos Estados. El Reglamento sobre la Transparencia no se aplica al arbitraje en el marco de un tratado existente a menos que los Estados partes convengan en aplicarlo por decisión unilateral, bilateral o conforme a una convención que elabore el Grupo de Trabajo II. En cambio, el Reglamento es aplicable a tratados futuros a menos que las partes decidan eximirse de dicha aplicación. Por supuesto, la CNUDMI debería alentar a los Estados partes en los tratados vigentes a que opten por aplicar el Reglamento sobre la Transparencia. Debería asimismo instar a las partes en arbitrajes individuales a que lo apliquen, así como compilar y difundir las buenas prácticas. Cabe esperar que la CNUDMI obtenga suficiente financiación para pasar a ser depositaria del Reglamento sobre la

Transparencia. Entre tanto, la Corte Permanente de Arbitraje convino en ser la depositaria. Por último, la CNUDMI podría realizar una evaluación periódica de la aplicación del Reglamento.

60. El **Sr. Chan Wah Teck** (Singapur) subraya la importancia del estado de derecho para que las personas sean conscientes de antemano respecto de las consecuencias de sus actos y tomen decisiones apropiadas. En su mayoría, las inversiones también deberían hacerse sobre la base de normas definidas. La certeza es fundamental y no deberían bajarse las expectativas. Toda modificación de las normas después de realizada una inversión constituiría una negación del concepto de estado de derecho. Por consiguiente, el orador acoge favorablemente la cláusula del Reglamento sobre la Transparencia que permite optar por su aplicación respecto de tratados existentes. Un factor crítico para determinar si un Estado se inclinaría por dicha aplicabilidad es el grado en que esa decisión contravendría las expectativas de los inversionistas y el efecto general que tendría en el concepto de estado de derecho.

61. **El Presidente** invita a la ponente Anna Joubin-Bret a hacer uso de la palabra. La Sra. Joubin-Bret cuenta con una experiencia profesional excepcionalmente variada como asesora jurídica de empresas multinacionales y Asesora Jurídica Superior de la División de la Inversión, el Fomento de la Empresa y la Tecnología de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Actualmente practica la abogacía en París, con especialización en derecho internacional de las inversiones y solución de controversias en materia de inversiones.

62. La **Sra. Joubin-Bret** (ponente) dice que centrará su intervención en la mediación para la solución pacífica de controversias económicas y el estado de derecho.

63. Una controversia o un conflicto puede resolverse mediante negociaciones directas entre las partes. Otra opción entraña la participación de una tercera parte, con tres posibles variantes. La primera consiste en la decisión de un tribunal; la segunda es el arbitraje internacional; y la tercera se basa en la conciliación y mediación. En los dos primeros casos, los adjudicadores neutrales tienen autoridad para obligar a las partes en litigio. En el tercer caso, que es también un proceso relativamente formal y estructurado, los conciliadores tienen el mandato de las partes para resolver la controversia, aunque la decisión final incumbe a las partes. La diferencia entre la conciliación y la mediación consiste en el papel que desempeña el tercero, cuya función en el caso de la

mediación es menos formal. El mediador alienta a las partes a interactuar y a proponer su propia solución.

64. Una de las ventajas de la solución de controversias por vías alternativas es que los resultados se obtienen más rápidamente. Además, es menos costosa y más flexible, dado que las propias partes acuerdan el procedimiento y ejercen un mayor control al respecto. Por ello, los agentes económicos y los inversionistas privados suelen preferir la solución de controversias por vías alternativas, pero con frecuencia los Estados también optan por el arbitraje.

65. La mediación y la conciliación no se utilizan lo suficiente debido a una falta de sensibilización sobre esa opción. Es más fácil, en particular para los Estados, remitir una controversia a una corte de justicia o un tribunal arbitral y ceñirse a la decisión o al laudo correspondiente. Otra desventaja de la mediación y la conciliación es la falta de ejecutoriedad. Además, podrían considerarse una pérdida de tiempo y de dinero si las partes no tienen realmente la intención de lograr una solución. Para los funcionarios de gobierno tal vez sea difícil también obtener un mandato firme para negociar y proponer una solución que pueda entrañar un traspaso de fondos.

66. El Banco Mundial realizó un estudio sobre la solución de controversias por vías alternativas en 101 economías. Su conclusión fue que solo siete de esas economías no disponían de un régimen consolidado de arbitraje comercial, conciliación o mediación. Solo cinco economías no contaban con instituciones capaces de administrar los casos de arbitraje. Los servicios de mediación y conciliación no se utilizaban con frecuencia. Sin embargo, la oradora se complace en señalar que muchas de las economías estudiadas aplican la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional.

67. Pasando a ofrecer ejemplos concretos, la oradora dice que en el marco de solución de controversias por vías alternativas vigente en Colombia la conciliación es un requisito previo a la apertura de un procedimiento judicial en casos de derecho comercial. Se celebra una audiencia preliminar en la que el juez actúa como conciliador. El 50% de los casos remitidos a conciliación se resuelve por esa vía. En el Ecuador existe una institución de mediación en la Fiscalía General que propone el recurso a la mediación a las partes en controversias comerciales tanto extranjeras como nacionales. La Autoridad General de Inversiones de Egipto dispone de una oficina de mediación que se utiliza principalmente para resolver controversias entre inversionistas en acuerdos de empresas conjuntas pero que puede atender también otro tipo de controversias relativas a inversiones. Por último la

República de Corea tiene un Ombudsman de Inversiones Extranjeras que media entre los organismos estatales y los inversionistas extranjeros.

68. El sistema preferido de solución de controversias internacionales en materia de inversiones es el arbitraje, dado que existe bastante desconfianza respecto del sistema de tratados y de los tribunales nacionales. Con todo, la oradora afirma que no se recurre lo suficiente a la mediación, la cual puede facilitar las soluciones amigables en una etapa temprana. Se estima que hasta la fecha se han presentado 450 casos de solución de controversias entre inversionistas y Estados. Esa cifra es muy superior al número de casos de conciliación resueltos en el marco del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados. Existe no obstante una fuerte tendencia a favor de la mediación como vía alternativa de solución de controversias relacionadas con inversiones. El arbitraje se considera un proceso innecesariamente largo y demasiado costoso. La oradora señala que el 39% de los casos que ha presentado a arbitraje internacional se resolvió antes de que se dictara un laudo definitivo. Así pues, fue posible hallar una solución mediante negociaciones al margen del procedimiento de arbitraje. En su opinión, esas negociaciones han de llevarse a cabo con transparencia y rendición de cuentas en el marco del estado de derecho.

69. Deberían adoptarse dos medidas para promover la aceptación de la mediación. En primer lugar, los marcos internos deberían incluir disposiciones legales para la mediación basadas en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional. En segundo lugar, es esencial fomentar la sensibilización con respecto a la mediación y crear la capacidad necesaria para su aplicación.

70. **El Presidente** dice que durante decenios se ha considerado que el arbitraje comercial, e incluso tal vez también el arbitraje en materia de inversiones, deberían ser confidenciales. Cabe preguntarse si puede haber transparencia en una mediación sobre inversiones.

71. La **Sra. Joubin-Bret** (ponente) dice que recientemente se han adoptado normas para la mediación entre inversionistas y Estados bajo los auspicios de la Asociación Internacional de Abogados. Esas normas incluyen disposiciones sobre confidencialidad y transparencia. Es evidente que cierto grado de transparencia es necesario en el contexto de los intereses de los Estados, que son desde luego también intereses públicos.

72. **El Presidente** invita al último ponente, Mohamed Abdel Wahab, a hacer uso de la palabra. El Sr. Abdel Wahab es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Cairo y se especializa en derecho internacional privado y solución de controversias. Es Vicepresidente de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres y Presidente de la Oficina para Egipto del Chartered Institute of Arbitrators. El Sr. Abdel Wahab también participó en las actuaciones del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI, relativo a la solución de controversias en línea.

73. El **Sr. Abdel Wahab** (ponente) dice que en su intervención expondrá principalmente cómo la solución de controversias en línea (ODR) puede contribuir al estado de derecho. La definición de la solución de controversias en línea tiene un carácter sumamente polémico, incluso entre los especialistas en la materia. No obstante, en el contexto del estado de derecho, la ODR es un medio innovador de promover la solución pacífica de controversias en un contexto internacional mediante procesos basados en la tecnología. Requiere el uso de tecnologías de vanguardia que forman parte de la evolución hacia una sociedad sin papel. Muchos proveedores de ODR han accedido al mercado mundial, especialmente en países desarrollados que disponen de la infraestructura necesaria. Sin embargo, su capacidad de competir se ha visto notablemente reducida. Mientras que en 2004 existían cerca de 115 proveedores, en 2013 su número se redujo a unos 63.

74. Los sistemas de ODR pueden dividirse en tres categorías básicas. La primera incluye los sistemas asistidos por medios tecnológicos, en los que el aspecto electrónico simplemente se integra en los procedimientos de negociación, mediación y arbitraje. Una segunda categoría consiste en mecanismos de ODR de carácter plenamente tecnológico e incluye las negociaciones automatizadas, en las que se introducen las variables en el sistema y este ofrece las soluciones óptimas para resolver la controversia. En tercer lugar, la ODR no solo contribuye a resolver las controversias sino también a evitarlas. Algunos sistemas en línea brindan un grado certeza y previsibilidad que permite reducir al mínimo los riesgos relacionados con las operaciones transfronterizas y de este modo ayudan a prevenir las controversias.

75. A juicio del orador, las actividades del Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea pueden abarcar las controversias interestatales e internas, lo que forma parte del mandato de ODR con respecto a la gobernanza mundial y el estado de derecho. Los instrumentos de las Naciones Unidas establecen las normas

necesarias y promueven la armonización. El orador insta a los representantes de los Estados que participan en actividades de establecimiento de normas a velar por el reconocimiento explícito de la contribución potencial de la tecnología a la solución de controversias y el estado de derecho en un contexto transnacional.

76. La ODR tiene otras ventajas como su accesibilidad permanente, la fiabilidad y la confianza en el proceso, la promoción de procedimientos de administración de justicia y soluciones ágiles, y la prevención eficaz y la gestión apropiada de las controversias. En circunstancias emocionales difíciles y situaciones de conflicto, cuando no es fácil persuadir a las partes de que se sienten a negociar, la ODR puede desempeñar un papel importante dado que permite entablar comunicaciones a la vez sincrónicas y asincrónicas a distancia. Además, es mucho más asequible que otros tipos de solución de controversias. En resumen, el orador afirma que la ODR puede tener un efecto dominó para el estado de derecho en todo el espectro político, económico, jurídico y social, lo que a su vez puede generar progresos y reformas en los contextos nacional e interestatal.

77. Debería elaborarse un conjunto paralelo de normas de ODR para las controversias y los conflictos interestatales. Si bien conviene mantener las formas tradicionales de solución de controversias, la tecnología permite incorporar dimensiones innovadoras en esos regímenes. Deberían asimismo formularse normas procesales y sustantivas y mecanismos de fomento de la confianza destinados a los proveedores de ODR. Aunque son una cuestión problemática para muchos Estados, los reglamentos promueven la confianza en el plano mundial y pueden significar para los proveedores la forma de

mantener sus operaciones. La globalización de la ODR en beneficio del estado de derecho requiere la formación de expertos en arbitraje que estén familiarizados con las demandas de la tecnología y con su integración en el proceso de solución de controversias.

78. **El Presidente**, resumiendo las cuestiones que han de reflejarse en el informe, dice que la Comisión reitera su convicción de que el estado de derecho en las relaciones comerciales debería formar parte integrante del programa más amplio en materia de promoción del estado de derecho en los planos nacional e internacional por conducto de los órganos competentes de las Naciones Unidas. La Comisión agradece al Presidente anterior por su intervención en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho y por su contribución al documento final. La secretaría pondrá a disposición de la Comisión una nota orientativa del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el fomento del estado de derecho en las relaciones comerciales, a la cual se dará amplia difusión. Se harán esfuerzos, por conducto de los diversos órganos de la CNUDMI, para reflejar las opiniones y la labor de la Comisión en los procesos en curso con miras a la formulación de la agenda internacional para el desarrollo después de 2015. Por último, en el informe se tomará nota de la decisión de la Asamblea General de que el tema de examen de la Sexta Comisión para 2014 sea “Puesta en común de las prácticas nacionales de los Estados para el fortalecimiento del estado de derecho mediante el acceso a la justicia”. Se invita a las delegaciones que lo deseen a que hagan llegar a la secretaría sus observaciones sobre el tema para su examen por la Comisión en su próximo período de sesiones.

Se levanta la sesión a las 16.55 horas.

II. BIBLIOGRAFÍA DE OBRAS RECIENTEMENTE PUBLICADAS RELATIVAS A LA LABOR DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

(A/CN.9/772)

[Original: inglés]

Índice

I.	Cuestiones generales
II.	Compraventa internacional de mercaderías
III.	Arbitraje y conciliación comercial internacional
IV.	Transporte internacional
V.	Pagos internacionales (incluidas las garantías independientes y las cartas de crédito contingente)
VI.	Comercio electrónico
VII.	Garantías reales (incluidos los créditos por cobrar)
VIII.	Contratación pública
IX.	Insolvencia
X.	Contratos internacionales de construcción
XI.	Comercio compensatorio internacional
XII.	Proyectos de infraestructura con financiación privada
XIII.	Solución de controversias en línea

I. Cuestiones generales

- Actas de la conferencia titulada «Traité internationaux relatifs au droit du commerce», 25 de noviembre de 2009, Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo. S.l., s.n., 2011. 67 páginas. Contenidos seleccionados: La théorie générale du droit des traités / A. Raharinarivonirina, páginas 8 a 22.
- Andenas, M. y C. B. Andersen, editores. *Theory and practice of harmonisation*. Cheltenham, Reino Unido, Edward Elgar, 2011. 617 páginas. Contenidos seleccionados: Demandeur-centricity in transnational commercial law / S. Gopalan — International commercial harmonisation and national resistance: the development and reform of transnational commercial law and its application within national legal culture / M. Heidemann — Towards a theory of harmonisation / M. Andenas, C. B. Andersen, R. Ashcroft.
- Bazinas, S. V. Business and human rights: the contribution of UNCITRAL. World Public Forum 'Dialogue of Civilizations' 10th Anniversary Session of the World Public Forum 'Dialogue of Civilizations', (Rodas, Grecia), 3 a 8 de octubre de 2012. Documento de conferencia.
- Brekoulakis, S. The impact of uniform law on Greek national law: limits and possibilities. *Revue hellénique de droit international = Hellenic review of international law* (Atenas) 64:2:797-831, 2011.
- Castellani, L. G. The contribution of uniform trade law to economic development and regional integration in East Asia and the Pacific: a view from UNCITRAL. *Dong-a journal of IBT law* (Busan, República de Corea) 8:31-46, 2012.
- Dickerson, C. Bibliography. Conferencia sobre legislación uniforme relativa a las empresas en África: contribución de la OHADA a la previsibilidad jurídica, 28 de marzo de 2012. Material de conferencia.
- Gombrii, K-J. CMI: champion of the unification of maritime law. *Boletín del BIMCO* (Bagsvaerd, Dinamarca) 107:1:64-67, 2012.
- Gross, C. M. News from the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL): UNCITRAL at the end of 2011. *Uniform law review = Revue de droit uniforme* (Roma) 16:4:1014-1023, 2011.
- Kwon, Jae-Jin. FTA와 UNCITRAL 아·태사무소. *MK business news* (República de Corea) 19 de marzo de 2012. Artículo sobre el establecimiento del Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico. En coreano.
- Lima, J. A. A Harmonização do Direito Privado. Brasília, Ministério das Relações Exteriores, 2008. 262 páginas. En portugués. Traducción del título: Armonización del derecho privado.
- Mandaloniz, M. G. No es oro todo lo que reluce en las microfinanzas: la necesidad de una regulación internacional. *Revista de derecho bancario y bursátil* (Valladolid, España) 127:103-159, 2012.
- Moollan, S. Nota de agradecimiento: Cóctel de recepción con motivo de la celebración del 56º período de sesiones del Grupo de Trabajo II de la CNUDMI (Arbitraje y Conciliación). *New York international chapter news* (Nueva York) 17:1:29, 2012.

- Naciones Unidas. Guía de la CNUDMI: Datos básicos y funciones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Viena, Naciones Unidas, 2013. 63 páginas. Puede consultarse en línea en la dirección: www.uncitral.org/uncitral/es/publications/publications.html.
- Osman, F., editor. *Vers une lex mercatoria mediterranea: harmonisation, unification, codification du droit dans l'Union pour la méditerranée*. Bruselas, Bruylant, 2012. 389 páginas. Contenidos seleccionados: *Le choix de la codification comme formule d'intégration régionale* / F. Zenati-Castaing, páginas 31 a 53 — *L'Union pour la Méditerranée et la circulation des modèles juridiques: une lecture du travail et de l'influence de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI)*/L. Ravillon, páginas 117 a 131.
- Salasky, J. News from the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL): UNCITRAL at the end of 2012. *Uniform law review = Revue de droit uniforme* (Roma) 17:4:745-755, 2012.
- Sandrock, O. Zum 100. Geburtstag von Pieter Sanders: Europäische Aktiengesellschaft - New Yorker Übereinkommen von 1958 — UNCITRAL. *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft* (Heidelberg, Alemania) 111:3:259-272, 2012. Traducción del título: Con motivo del centenario del nacimiento de Pieter Sanders: Societas Europaea — Convención de Nueva York de 1958 — CNUDMI.
- Sikirić, H. Declaración ante la Sexta Comisión de la Asamblea General, 15 de octubre de 2012. Puede consultarse en línea en <http://papersmart.unmeetings.org/en/ga/sixth/67th-session/statements/>.
- _____. Declaración del Presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en su 45º período de sesiones, Sr. Hrvoje Sikirić, durante la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho a nivel nacional e internacional, celebrada el 24 de septiembre de 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: http://unrol.org/files/Statement_UNCITRAL.pdf.
- Sorieul, R. Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico. *Recent trends of law & regulation in Korea* (Gwacheon, República de Corea) 6:6:24-25, 2012.
- Stewart, D. P. Private international law, the rule of law, and economic development. *Villanova law review* (Villanova, Pa.) 56:607-630, 2011.
- Twigg-Flesner, C. y G. Villalta Puig, editores. *Boundaries of commercial and trade law*. Munich, Sellier, 2011. 204 páginas. Contenidos seleccionados: *Some thoughts on the harmonisation of commercial law and the impact on cross-border transactions* / C. Twigg-Flesner.
- Wharton, N. *Fundamentals of transnational business law*. Lexington, Ky., s.n., 2012. 325 páginas.

II. Compraventa internacional de mercaderías

Accaoui Lorfing, P. *La renégociation des contrats internationaux*. Bruselas, Bruylant, 2011. 451 páginas.

Actas de la conferencia titulada «Traités internationaux relatifs au droit du commerce», 25 de noviembre de 2009, Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo. S.l., s.n., 2011. 67 páginas. Contenidos seleccionados: Pour la promotion de l'adoption de la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises (artículo publicado en 2009) / L. Castellani, páginas 35 a 42.

Alaoudh, A. S. The notice requirement of Article 39 and Islamic law: developed vs. developing countries. *Arab law quarterly* (Londres) 26:4:481-498, 2012.

Al-Masadeh, N. The possibility of applying the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods by a Jordanian judge. *Arab law quarterly* (Londres) 26:3:381-386, 2012.

Andenas, M. y C. B. Andersen, editores. *Theory and practice of harmonisation*. Cheltenham, Reino Unido., Edward Elgar, 2011. 617 páginas. Contenidos seleccionados: Applied uniformity of a uniform commercial law: ensuring functional harmonisation of uniform texts through a global jurisconsultorium of the CISG / C. B. Andersen — Methodological challenges of codifying or consolidating national and international sales law based on CISG Article 35 / R. F. Henschel — Achieving optimal use of harmonisation techniques in an increasingly interrelated twenty-first century world-consumer sales: moving the EU harmonisation process to a global plane / L. Del Duca, A. H. Kritzer, D. Nagel — Harmonised legal framework for carbon trading / B. Zeller.

Andersen, C. B. Article 39 of the CISG and its 'noble month' for notice-giving: a (gracefully) ageing doctrine? *Journal of law and commerce* (Pittsburgh, Pa.) 30:2:185-202, 2012.

_____. Recent removals of reservations under the international sales law: winds of change heralding a greater unity of the CISG. *Journal of business law* (Londres) 8:699-712, 2012.

Asghari, M. B. y otros. The consequence of passing of risk in contracts of sale involve carriage of goods: a comparative study between Iranian law and CISG. *International proceedings of economics development and research* (Singapur) 36:101-104, 2012.

Atipo, A. P. Force majeure in international business: a comparative assessment of force majeure under the UCC and the UNCISG. *CAR: CEPMLP annual review* (Dundee, Escocia) 2008/2009.

Australia. Attorney-General's Department. Improving Australia's law and justice framework: a discussion paper to explore the scope for reforming Australian contract law. Barton, Australia, Commonwealth of Australia, 2012. 29 páginas.

- Baddeley, M. y otros, editores. Le droit civil dans le contexte international: journée de droit civil 2011. Ginebra, Schulthess, 2012. 216 páginas. Contenidos seleccionados: La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM) a-t-elle pénétré le droit suisse? / C. Chappuis, páginas 183 a 209.
- Van Baren, L. y A. Trofymenko. Conference report: '20 years of CISG in the Netherlands', Amsterdam, 20 de abril de 2012. *European review of private law* = *Revue européenne de droit privé* = *Europäische Zeitschrift für Privatrecht* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 20:4:1171-1178, 2012.
- Başoğlu, B. Türk hukukunda ve mukayeseli hukukta aynen ifa talebi. Estambul, XII Levha, 2012. 292 páginas. Traducción del título: Cumplimiento estricto en el derecho turco y comparado.
- Begaiym, E. Formation of contract for the international sale of goods: comparative study of the CISG and legislation of the Kyrgyz Republic. Budapest, CEU, 2009. 91 páginas. Tesis (LL.M.) — Central European University, 2009.
- Bell, G. F. Harmonisation of contract law in Asia: harmonising regionally or adopting global harmonisations, the example of the CISG. *Singapore journal of legal studies* (Singapur) 2005:362-372.
- Bernstein, L. An (un) common frame of reference: an American perspective on the jurisprudence of the CESL. Conference on European Contract Law: A Law-and-Economics Perspective, Universidad de Chicago, 27 y 28 de abril de 2012. Documento de conferencia.
- Bolzonello, L. The 'validity exception' in the CISG and remedies for mistake in domestic contract law: preemption and concurrence. *Social science research network* 15 de mayo de 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://ssrn.com/abstract=2121714>.
- Bonelli, F. Il «risarcimento dei danni» nei principi UNIDROIT, nella Convenzione di Vienna del 1980 e nel diritto italiano. *Diritto marittimo* (Genova, Italia) 114:3:687-699, 2012. Traducción del título: Resarcimiento por daños según los Principios UNIDROIT, la CIM de 1980 y el derecho italiano.
- Booz, Allen [y] Hamilton (Nueva York). Reinforcing Ethiopia's international trade law framework for a stronger business environment: a case for the ratifications of the New York Convention and the CISG. S.I., USAID, 2008. 27 páginas.
- Boucard, H. La unificación internacional del derecho del contrato de compraventa y su irradiación europea. *Revista electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada* (Granada, España) 1 de marzo de 2008.
- Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão de Relações Exteriores. Projecto de decreto legislativo, N.º 222-A, DE 2011, Mensagem No 636/2010, Aviso No 772/2010 – C. Civil. S.I., Câmara dos Deputados, 2011. 75 páginas. Informe que incluye la CIM (1980) en portugués e informe analítico sobre la CIM (1980) de la Cámara de Comercio. Incluye un anexo con un gráfico que compara la CIM (1980) con la legislación interna. En portugués.

- Cafaggi, F. CESL and pre-contractual liability: from a status to a transaction-based approach. Conference on European Contract Law: A Law-and-Economics Perspective, University of Chicago, 27 y 28 de abril de 2012. Documento de conferencia.
- Cámara de Comercio e Industria de Viet Nam. Cong uoc cua Lien Hop Quoc ve hop dong mua ban quoc te (Cong uoc vien 1980). Hanoi, Cámara de Comercio e Industria de Viet Nam, 2012. 29 páginas. Traducción de la CIM (1980). En vietnamita. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://trungtamwto.vn/vandedacbiet/cong-uoc-vien/cong-uoc-vien-ve-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te>.
- Consejo Asesor de la CIM, Declaración N° 1 del Consejo Asesor de la CIM sobre la CIM y la armonización regional. Puede consultarse en línea en la dirección: www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-dec1.html.
- _____. Consejo Asesor de la CIM: Opinión N° 11 del Consejo Asesor de la CIM sobre las cuestiones planteadas en los documentos sobre la CIM relacionados con las obligaciones de pago del comprador. Puede consultarse en línea en la dirección: www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op11.html.
- Clive, E. M. Switzerland proposes future work by UNCITRAL on international contract law. *European private law news* (Edinburgh, Reino Unido) 18 de mayo de 2012.
- Complexity of transnational law. *European review of private law = Revue européenne de droit privé = Europäische Zeitschrift für Privatrecht* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 20:1:3-194, 2012. Journal section. Contenidos seleccionados: General report: complexity of transnational sources / S. Ferreri, págs. 3 a 50 — Austrian report / B. Verschraegen, págs. 51 a 80 — Canadian report / H. Dedek, A. Carbone, págs. 81 a 100 - German report / E-M. Kieninger, K. Linhart, págs. 101-122 — Hungarian report / G. Suto Burger, págs. 123 a 138 - Japanese report / Tetsuo Morishita, págs. 139 a 152 — Dutch report: coherence and fragmentation of private law / J. Smits, págs. 153 a 168 — OHADA report / S. Mancuso, págs. 169 a 184 — Swiss report / A. Fötschl, págs. 185 a 194.
- Costa, M. Portugal e a Convenção de Viena sobre a Compra e Venda Internacional de Mercadorias. *Visão* (Lisboa) 8 de marzo de 2012. Traducción del título: Portugal y la CIM (1980).
- Darankoum, E. S. Méthode de mise en oeuvre de la convention de Vienne sur la vente internationale: l'arbitrage OHADA au prisme de la pratique CCI. *Penant: revue trimestrielle de droit africain* (Paris) 122:881:497-530, 2012.
- Dawwas, A. Anticipatory avoidance of contract: CISG and Egyptian law compared. *Nordic journal of commercial law* (Turku, Finlandia) 1:2012.
- _____. Non-conformity of goods in light of CISG, Unidroit Principles and the Palestinian commercial law draft. *Journal of sharia & law* (Al Ain, Emiratos Árabes Unidos) 52:25-80, 2012.
- Dawwas, A. y Y. Shandi. The applicability of the CISG to the Arab world. *Uniform law review = Revue de droit uniforme* (Roma) 16:4:813-841, 2011.

- Dedek, H. y A. Carbone. Canadian report. *European review of private law* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 20:1:81-100, 2012.
- DiMatteo, L. A. The scholarly response to the harmonization of international sales law. *Journal of law and commerce* (Pittsburgh, Pa.) 30:1:1-22, 2011.
- Do, Minh Anh. La cuestión de la modificación del concepto de compraventa internacional de mercaderías en el derecho mercantil para adherir a la CIM (1980). *Tap chi Luat hoc* (Viet Nam) 9:3-9, 2011. En vietnamita. Título traducido del inglés. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://luathoc.vnweblogs.com/post/19665/333789>.
- Douglas, J. Arbitration of international sale of goods disputes under the Vienna Convention. *Arbitrator & mediator* (Melbourne) 27:1:15-24, 2008.
- Draetta, U. La Convention des Nations Unies de 1980 sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises et l'arbitrage = The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and arbitration. *Revue de droit des affaires internationales = International business law journal* (París) 2:193-205, 2012.
- Duhl, G. M. International sale of goods 2011. *Social science research network* 12 de junio de 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://ssrn.com/abstract=2083276>.
- Eberl-Borges, C. y Su Yingxià. 12 Jahre chinesisches Vertragsgesetz: zur heutigen Bedeutung der Vertragsfreiheit in China. *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft* (Heidelberg, Alemania) 111:2:125-153, 2012. Traducción del título: Doce años de derecho contractual chino; el significado actual de la palabra libertad de contratos en China.
- Falla Armenteros, A. The regulation on a common European sales law: chronicle of a death foretold. Estrasburgo, Francia, Universidad de Estrasburgo, 2012. 52 páginas. Tesis (máster) — Universidad de Estrasburgo, 2012.
- Ferrari, F. PIL and CISG: friends or foes? *Internationales Handelsrecht* (Munich) 12:3:89-113, 2012.
- Fornasier, M. »28.« versus »2. Regime«: Kollisionsrechtliche Aspekte eines optionalen europäischen Vertragsrechts. *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* (Tübingen, Alemania) 76:2:401-442, 2012. Traducción del título: '28º versus 2º régimen: derecho contractual europeo facultativo desde la perspectiva de la elección del derecho.
- Gabriel, H. D. Proposal for a UNCITRAL project on global contract law: State Department Advisory Committee on Private International Law Annual Meeting, 11 y 12 de octubre de 2012, The George Washington University Law School, Washington, DC. Documento de conferencia.
- Giermanski, J. R. The global supply chain and its commercial and security elements. En J. R. Giermanski. *Global supply chain security*. Plymouth, Reino Unido, Scarecrow Press, 2013. Páginas 105 a 116.
- Göler, J. von y F. Lüth. The passing of legal risk under the Vienna Sales Convention: does article 66 CISG cover acts of state? *Vindobona journal of international commercial law and arbitration* (Viena) 16:1:19-34, 2012.

- Gössl, S. L. y J. A. Bischoff. Regional vs. universal unification? *Transnational notes* (Nueva York) 23 de agosto de 2012.
- Graves, J. Penalty clauses and the CISG. *Journal of law and commerce* (Pittsburgh, Pa.) 30:2:153-172, 2012.
- Hassan, H. F. لحظة انعقاد العقد طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي ١٩٨٠ - للبضائع *Journal of science for law* (Baghdad) 2010:2:194-241. Traducción del título: El momento de la conclusión de un contrato según la CIM (1980).
- Heidemann, M. European private law at the crossroads: the proposed European Sales Law. *European review of private law = Revue européenne de droit privé = Europäische Zeitschrift für Privatrecht* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 20:4:1119-1138, 2012.
- Hellwege, P. Die Geltungsbereiche des UN-Kaufrechts und des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts im Vergleich. *Internationales Handelsrecht* (Munich) 12:5:180-186, 2012. Traducción del título: El ámbito de aplicación de la CIM (1980) y comparación con el derecho común europeo de compraventa.
- _____. UN-Kaufrecht oder Gemeinsames Europäisches Kaufrecht? *Internationales Handelsrecht* (Munich) 12:6:221-231, 2012. Traducción del título: ¿La CIM (1980) o el derecho común europeo de compraventa?
- Hesselink, M. W. How to opt into the Common European Sales Law? Brief comments on the Commission's proposal for a regulation. *European review of private law = Revue européenne de droit privé = Europäische Zeitschrift für Privatrecht* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 20:1:195-211, 2012.
- Heuzé, V. Le technocrate et l'imbécile: essai d'explication du droit commun européen de la vente. *Semaine juridique édition générale* (París) 25:1225-1232, 2012.
- Huang, Yanming. Two notes on the application of the CISG to cases under the jurisdiction of the CIETAC South China. *Mealey's international arbitration report* (King of Prussia, Pa.) 27:9:19-29, 2012.
- Irlanda. Sales Law Review Group. Report on the legislation governing the sale of goods and supply of services. Dublin, Stationary Office, 2011. 568 páginas.
- Iversen, T. Scandinavian contract law and its implication on CISG: the Danish approach. *Scandinavian studies in law* (Estocolmo) 57:107-115, 2012.
- Janssen, A. y L. A. DiMatteo. Interpretive uncertainty: methodological solutions for interpreting the CISG. *Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht* (Zutphen, Países Bajos) 2:52-69, 2012.
- Janssen, A. y M. Spilker. The application of the CISG in the world of international commercial arbitration. *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* (Tübingen, Alemania) 77:1:131-157, 2013.
- Jenkins-Hobbs, S. H. Construing laws governing international and U.S. domestic contracts for the sale of goods: a comparative evaluation of the CISG and UCC rules of interpretation. *ExpressO* 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: http://works.bepress.com/sarah_jenkins-hobbs/5.

- Johnson, W. P. The hierarchy that wasn't there: elevating 'usage' to its rightful position for contracts governed by the CISG. *Northwestern journal of international law and business* (Chicago, Ill.) 32:2:263-303, 2012.
- Kapitán, Z. Podmínky aplikovatelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. *Právní fórum* (Praha) 5:7:275-289, 2008. Traducción del título: Condiciones aplicables a la CIM (1980).
- Kawakami, M. Informe de la conferencia: 'Competition in international sales law — perspectives on choice', celebrada en Maastricht, Países Bajos, el 15 de junio de 2012. *European review of private law = Revue européenne de droit privé = Europäische Zeitschrift für Privatrecht* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 21:1:387-396, 2013.
- Khramov, D. Последствия нарушения договора международной купли-продажи. *Корпоративный юрист* (Москва) 12:6:44-48, 2012. Traducción del título: Consecuencias de la violación del contrato de compraventa internacional de mercaderías.
- Klett, B. Compravendita internazionale e Convenzione di Vienna. *Rivista* (Zürich) 12:39-41, diciembre de 2010. Traducción del título: Compraventa internacional y la CIM (1980).
- Kordjazi, H. y otros. Loss of profit in breach of contract: comparative study between Iran and Convention of International Sale of Goods (1980). *International proceedings of economics development and research* (Singapur) 31:150-153, 2012.
- Kornet, N. The Common European Sales Law and the CISG: complicating or simplifying the legal environment? *Maastricht European Private Law Institute* (Maastricht, Países Bajos) documento de trabajo No. 2012/4, marzo de 2012.
- Kötz, H. Contract law in Europe and the United States: legal unification in the civil law and common law. *Tulane European and civil law forum* (Nueva Orleans, La.) 27:1-16, 2012.
- Kröll, S. y otros, editores. International arbitration and international commercial law: synergy, convergence and evolution, [liber amicorum Eric Bergsten]. Alphen aan den Rijn, Países Bajos, Kluwer Law International, 2011. 842 páginas. Contenidos seleccionados: Consequences of avoidance under the CISG / M. Dimsey — Declaration of price reduction under the CISG: much ado about nothing? / M. Djordjević — Excluding CISG article 35(2) quality obligations: the 'default rule' view vs the 'cumulation' view / H. M. Flechtner/ Surprising terms in standard contracts under the CISG / R. Koch — The CISG 'Secretariat Commentary': has it stood the test of time? / F. G. Mazzotta, V. M. Rogers — The CISG: a lex amicorum / J. F. Morrissey — Avoidance for non-conformity of goods under art. 49(1)(a) CISG / M. Müller-Chen, L. M. Pair — Bergsten's mark on the law's international reasonable person / E. Opie.
- Lando, O. Tradition versus harmonization in the recent reforms of contract law. *Collected courses of the Xiamen Academy of International Law* (Leiden, Países Bajos) 3:87-154, 2010.

- Lookofsky, J. M. *Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*. Alphen aan den Rijn, Países Bajos, Kluwer Law International, 2012. 224 páginas.
- _____. The CISG in Denmark and Danish courts. *Nordic journal of international law* (Leiden, Países Bajos) 80:295-320, 2011.
- _____. Understanding the CISG: a compact guide to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 4^a ed. (a nivel mundial) Alphen aan den Rijn, Países Bajos, Kluwer Law International, 2012. 239 páginas.
- Loos, M. B. M. y H. N. Schelhaas. Commercial sales: the Common European Sales Law compared to the Vienna Sales Convention. *European review of private law = Revue européenne de droit privé = Europäische Zeitschrift für Privatrecht* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 21:1:105-130, 2013.
- Maduekwe, N. The CISG and Nigeria: is there a meeting point? *CAR: CEPMLP annual review* (Dundee, Escocia) 2009/2010.
- Magnus, U. CISG y CESL. *Max Planck private law research paper* (Hamburgo) 12/27, 1 de septiembre de 2012.
- _____. The Scandinavian reservation under Art. 92 CISG. *Scandinavian studies in law* (Estocolmo) 57:195-216, 2012.
- Magnus, U., editor. CISG vs. regional sales law unification: with a focus on the new Common European Sales Law. Munich, Sellier European Law Publishers, 2012. 237 páginas. Contents: Introduction / U. Magnus — The U.S. experience with the UCC and the CISG: some insights for the proposed CESL? / H. M. Flechtner — The curious case of transborder sales law: a comparative analysis of CESL, CISG, and the UCC / L. A. DiMatteo — The CISG and the common law: the Australian experience / B. Zeller — CISG and OHADA Sales Law / F. Ferrari — CISG vs. CESL / U. Magnus — CISG, CESL, PICC and PECL / R. Koch — Concluding remarks / U. Magnus — Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law.
- Mahasneh, N. The ratification of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods by Jordan: the legal perspective and impact. *Uniform law review = Revue de droit uniforme* (Roma) 16:4:843-865, 2011.
- Mankowski, P. CESL: who needs it? *Internationales Handelsrecht* (Munich) 12:2:45-53, 2012.
- Martin, J. S. Does Article 2 inform CISG damages? *Social science research network* 11 de octubre de 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://ssrn.com/abstract=2160344>.
- Mazzacano, P. J. The treatment of CISG Article 79 in German courts: halting the homeward trend. *Nordic journal of commercial law* (Turku, Finlandia) 2:2012.
- Meira Moser, L. G. Albert H. Kritzer, the 1980 UN Convention (CISG), and the Vis Moot: an inseparable relationship. *Pace international law review* (White Plains, N.Y.) 24:1:258-265, 2012.

- Mengliev, C. Гармонизация гражданско-правовых норм стран СНГ. *zakon.kz* (Kazakhstan) 27 de enero de 2012. Traducción del título: Armonización del derecho civil en los países de la CEI. Puede consultarse en línea en la dirección: www.zakon.kz/4470169-garmonizacija-grazhdansko-pravovyykh.html.
- Momberg Uribe, R. Change of circumstances in international instruments of contract law: the approach of the CISG, PICC, PECL and DCFR. *Vindobona journal of international commercial law and arbitration* (Viena) 15:2:233-266, 2011.
- _____. Compraventa internacional de mercaderías: el deber de renegociación en caso de excesiva onerosidad sobrevenida. *Revista Chilena de derecho privado* (Santiago) 18:95-119, 2012.
- Moreno Rodríguez, J. A. Contracts and non-state law in Latin America. *Uniform law review* = *Revue de droit uniforme* (Roma) 16:4:877-889, 2011.
- Munasinghe, I. K. The importance of the ratification and adoption of the Vienna Convention for the International Sale of Goods (CISG). *Proceedings ICME* (Sahiwal, Pakistán) 1:132-140, 2012.
- Naciones Unidas. CNUDMI. Compendio de jurisprudencia relativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, 2012. Nueva York, Naciones Unidas, 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: www.uncitral.org/uncitral/es/publications/publications.html.
- Nain, Y. y S. Manish. Why India should opt for CISG. *India law journal* (India) 4:3, 2011.
- Neumann, T. Chinese success and failure in achieving uniform application of the CISG. *Vindobona journal of international commercial law and arbitration* (Viena) 16:1:83-94, 2012.
- Newhouse, A. y Tsuneyoshi Tanaka. CISG: a tool for globalization (1): American and Japanese perspectives. *Ritsumeikan law review* (Kyoto, Japón) 29:1-41, 2012.
- Nguyen, Minh Hang y Thi My Loan Dinh. De xuat Viet Nam gia nhap Cong uoc Vien ve hop dong mua ban hang hoa quoc te. Hanoi, VCCI, 2010. 77 páginas. En vietnamita. Traducción del título: Estudio sobre la adhesión de Viet Nam a la CIM (1980). Puede consultarse en línea en la dirección: <http://trungtamwto.vn/vandedacbiet/cong-uoc-vien/de-xuat-viet-nam-gia-nhap-cong-uoc-vien-ve-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc>.
- Nguyen, Trung Nam y otros. Viet Nam tham gia Cong uoc Vien 1980 ve Hop dong mua ban hang hoa quoc te (CISG): Loi ich va Han che. Hanoi, EP Legal, 2010. 25 páginas. En vietnamita. Traducción del título: La adhesión de Viet Nam a la CIM (1980): beneficios y limitaciones. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://trungtamwto.vn/vandedacbiet/cong-uoc-vien/viet-nam-tham-gia-cong-uoc-vien-1980-ve-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te>.

- Niibori, Satoshi. グローバル商取引法各論: ウィーン売買条約後の国際商取引法統一の行方: 条約からリステイトメントへ. *JCA ジャーナル = JCA journal* (Tokio) páginas 30 a 33, vol. 58, 2011. En japonés. Traducción del título: Temas de derecho comercial mundial, armonización del derecho mercantil internacional con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa (1980): del tratado a la reformulación.
- Nikolova, S. E. UK's ratification of the CISG: an old debate or a new hope for the economy of the UK on its way out of the recession: the potential impact of the CISG on the UK's SME. *Pace international law review online companion* (Nueva York) 3:3:69-110, 2012.
- Nwafor, N. A. Analysis of buyer's obligations under Articles 38 and 39 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). *Social science research network*, 27 de diciembre de 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://ssrn.com/abstract=2194101>.
- _____. Whither the CISG?: case for its acceptance in Nigeria. *Social science research network*, 23 de diciembre de 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://ssrn.com/abstract=2193316>.
- Oh, Se-Chang. Artículos en coreano sobre la CIM (1980) y la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos electrónicos (2005). S.l., s.n., 2001. 1 v. Contenidos seleccionados: 청약과 관련한 CISG규정하에서 이루어지는 전자통신에 유엔전자협약 적용시 유의사항. 한국무역상무학회 38:3-45, 30 de mayo de 2008. Traducción del título: Información importante sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos electrónicos (2005) con arreglo a la CIM (1980) — 국제물품매매협약(CISG)에 전자통신협약 (CUECIC) 적용시 국제 전자계약의 효력발생을 위한 전제조건에 관한 연구. 계명대학교 산업경영연구소 경영경제 4(2):45-81, agosto de 2008. Traducción del título: Condiciones necesarias para dar efectividad a la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos electrónicos (2005) con arreglo a la CIM (1980) - CUECIC상의 법적 효력을 위한 형식요건에 관한 연구. 계명대학교 산업경영연구소 경영경제 41(1):193-212, febrero de 2008. Traducción del título: Requisitos de forma para dar fuerza de ley a la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos electrónicos (2005) - 유엔전자통신협약상의 최종규정에 대한 소고. 계명대학교 산업경영연구소 경영경제 42(1):137-163, febrero de 2009.
- Osaka Bar Association. International Practice Study Group. 国際物品売買契約に関する国際連合条約(C I S G)のシリーズ解説 [9-18]. *Kokusai shoji homu* (Tokio) Puntos 9 a 18 en el volumen 40, 2012. En japonés. Traducción del título: Guía práctica de la CIM (1980): mediante una comparación con el derecho civil y mercantil japonés.
- Oviedo Albán, J. El carácter internacional y la interpretación uniforme de la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. *Boletín Mexicano de derecho comparado* (México, D.F.) 133:253-282, 2012.
- Peluso, M. A. Convention on Contracts for the International Sale of Goods: an example of successful international commercial diplomacy. *Magazine for international business and diplomacy* (Londres) 3 de marzo de 2011.

- Permatz, C. Seller's right to cure under the United Nations Convention for the International Sale of Goods (CISG). Sölvegaten, Suecia, Universidad de Lund, 2011. 70 páginas. Tesis (máster) — Universidad de Lund, 2011.
- Peters, M. S. y M. Kumar. Are the Principles of European Contract Law an autonomous lex mercatoria, or are they part of universal lex mercatoria? *European journal of commercial contract law* (Zutphen, Países Bajos) 4:1:1-7, 2012.
- Piers, M. y J. Erauw. Application of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts in arbitration. *Journal of private international law* (Oxford, Reino Unido) 8:3:441-472, 2012.
- Piltz, B. Sales involving carriage of the goods. *Nederlands tijdschrift voor handelsrecht* (Zutphen, Países Bajos) 2:86-88, 2012.
- . The proposal for a regulation on a Common European Sales Law and more particular its provisions on remedies. *Internationales Handelsrecht* (Munich) 12:4:133-136, 2012.
- . The proposal for a regulation on a common European sales law: provisions on remedies, note. Bruselas, Unión Europea, 2012. 13 páginas.
- Pirozzi, R. Developments in the change of economic circumstances debate? *Vindobona journal of international commercial law and arbitration* (Viena) 16:1:95-112, 2012.
- Ramberg, C. Problems legal practitioners face in finding the law relating to CISG: hardship, defective goods and standard terms. *Scandinavian studies in law* (Estocolmo) 57:283-291, 2012.
- Ramberg, J. UPICC and CISG. *Diritto del commercio internazionale* (Genova, Italia) 26:4:865-871, 2012.
- Regional conference on 'harmonization of the law: the Hague Conference, Unidroit and UNCITRAL': Beirut Arab University, [10 y 11 de septiembre de 2012], Beirut, Líbano [material de conferencia]. Beirut, Beirut Arab University, 2012. CD-ROM. Contenidos seleccionados: The scope of the application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980 (Vienna Convention) / Abdullah Abdulkarim Abdullah — L'harmonisation du droit des contrats «plus que jamais nécessaire» à une intégration régionale des pays maghrébins / Bel Haj Hamouda Ajmi.
- Remien, O., editor. Verjährungsrecht in Europa - zwischen Bewährung und Reform: Würzburger Tagung vom 8. und 9.5.2009. Tübingen [Alemania], Mohr Siebeck, 2011. 419 páginas. Contenidos seleccionados: Limitation in the international arena: the United Nations Limitation Convention for International Sales / U. Magnus. En alemán y en inglés. Traducción del título: Legislación europea sobre prescripción: entre preservar y reformar.
- Riznik, P. Article 77 CISG: reasonableness of the measures undertaken to mitigate the loss. København, s.n., 2009. xviii, 52 páginas. Tesis doctoral — Københavns Universitet det Juridiske Fakultet, 2009.

- Rogowska, A. The UNIDROIT Principles and PECL: experiences in English academic circles. *Uniform law review = Revue de droit uniforme* (Roma) 16:4:867-875, 2011.
- Rudolf, C. Befreiung von der Untersuchungsobliegenheit nach Art 38 CISG. *Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung* (Wien) 53:5:218-222, 2012. Traducción del título: Exención del examen previsto en el artículo 38 de la CIM (1980).
- Saba, N. To believe or not to believe: good faith in the CISG. *Macquarie journal of business law* (Sidney) 9:81-87, 2012.
- Sandvik, B. The battle for the consumer: on the relation between the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the EU Directives on Consumer Sales. *European review of private law = Revue européenne de droit privé = Europäische Zeitschrift für Privatrecht* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 20:4:1097-1118, 2012.
- Schroeter, U. G. The cross-border freedom of form principle under reservation: the role of Articles 12 and 96 CISG in theory and practice. *Social science research network* 31 de octubre de 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://ssrn.com/abstract=2169834>.
- Schwenzer, I. The proposed Common European Sales Law and the Convention on the International Sale of Goods. *Uniform commercial code law journal* (Nueva York) 44:4:457-481, 2012.
- Schwenzer, I. y P. Hachem. Drafting new model rules on sales: CFR as an alternative to the CISG? *European journal of law reform* (La Haya) 11:4:459-472, 2012.
- Sisula-Tulokas, L. Nordic hesitancy regarding part II of the CISG. *Scandinavian studies in law* (Estocolmo) 57:293-295, 2012.
- Smits, J. M. Problems of uniform sales law: why the CISG may not promote international trade. *Maastricht European Private Law Institute working paper* (Maastricht, Países Bajos) 2013:1.
- Spanogle, J. A. y P. Winship. International sales law: a problem-oriented coursebook. 2a. ed. St. Paul, Minn., West, 2012. 384 páginas. Incluye referencias e índices bibliográficos.
- Stone, B. y S. González Luna M. Aggrieved buyer's right to performance or money damages under the CISG, U.C.C., and Mexican Commercial Code. *Journal of law and commerce* (Pittsburgh, Pa.) 30:1:23-85, 2011.
- Sumulong, V. International trade law and the United Nations Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods. *Philippine law journal* (Ciudad Quezon, Filipinas) 50:318-371, 1975.
- Taylor, D. Reflections on a critical aspect of CISG-governed international sale of goods transactions: the impact of the Hague Convention on choice of court agreements on forum selection. *International trade and business law review* (Abington, Oxfordshire, Reino Unido) 15:42-59, 2012.

- Tietje, C. y E. Sipiorski. Offset of benefits in damages calculation in international investment arbitration. *Journal of international arbitration* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 29:5:545-566, 2012.
- Viet Nam va Cong uoc Vien 1980 ve Hop dong mua ban hang hoa quoc te. *Ban tin Doanh nghiep va Chinh sach Thuong mai Quoc te* (Hanoi) 3-4:15-26, 2010. Sección especial de la revista. En vietnamita. Traducción del título: Viet Nam y la CIM (1980). Puede consultarse en línea en la dirección <http://wtocenter.vn/vien-convention/enterprises-and-international-trade-policy-newsletter-no-3-no4>.
- Viet Nam. Ministerio de Industria y Comercio. Bao cao nghien cuu kha nang Viet Nam gia nhap Cong uoc Vien 1980 ve Hop dong mua ban hang hoa quoc te (CISG). Hanoi, Ministerio de Industria y Comercio, 2011. 50 páginas. En vietnamita. Traducción del título: Estudio sobre la posible adhesión de Viet Nam a la CIM (1980).
- Vilkova, N. G. The unification of conflict of law rules in the CIS countries. *Review of Central and East European law* (Leiden, Países Bajos) 26:1:75-83, 2000.
- Vogenauer, S. Regulatory competition through choice of contract law and choice of forum in Europe: theory and evidence. *European review of private law = Revue européenne de droit privé = Europäische Zeitschrift für Privatrecht* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 21:1:13-78, 2013.
- Weiler, T. y F. Baetens, editores. New directions in international economic law: in memoriam Thomas Wälde. Leiden, Países Bajos, Martinus Nijhoff Publishers, 2011. 591 páginas. Contenidos seleccionados: The transnational law of contracts: what it can and what it cannot achieve / G. Cordero-Moss, páginas 45 a 78.
- Weitz, Y. M. y L. Tam. International art transactions under CISG. *Art & advocacy* (Nueva York) 13:4-7, 2012.
- Weller, M-P. y C. S. Harms. Der Primat der Nacherfüllung im Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht. *GPR-Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht* (Munich) 9:6:298-308, 2012. Traducción del título: La primacía del recurso en la normativa común europea de compraventa.
- Wihlborg, C. Det nordiska lagstiftningssamarbetet i relation till FN- konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Lund, Suecia, Universidad de Lund, 2011. 35 páginas. Traducción del título: Cooperación nórdica en asuntos legislativos en relación con la CIM (1980).
- Winship, P. Harmonizing formal requirements for cross-border sales contracts. *International review of law* 2012:6, 25 de Julio de 2012.
- _____. Should the United States withdraw its CISG article 95 declaration?: State Department Advisory Committee on Private International Law Annual Meeting, October 11-12, 2012, The George Washington University Law School, Washington, DC. Ponencia.

- Witz, C. CISG France: applications jurisprudentielles de la Convention de Vienne en France [electronic resource]. 2a. ed. Sarrebruck, [Alemania], s.n., 2012. Base de datos de jurisprudencia francesa sobre la CIM (1980). Puede consultarse en línea en la dirección: www.cisg.fr.
- _____. Droit uniforme de la vente internationale de marchandises. *Recueil Dalloz* (París) 188:18:1144-1157, 2012.
- Wolff, R. New York Convention: Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 10 June 1958: commentary. Munich, C.H. Beck, 2012. 613 páginas.
- Yang, Fan. A uniform sales law for the Mainland China, Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan: the CISG. *Vindobona journal of international commercial law and arbitration* (Viena) 15:2:345-364, 2011.
- _____. Contracts for the international sale of goods in China. Hong Kong, CCH Hong Kong Limited, 2012. 375 páginas.
- Zeller, B. Intellectual property rights & the CISG Article 42. *Vindobona journal of international commercial law and arbitration* (Viena) 15:2:289-302, 2011.
- _____. When is a fixed sum not a fixed sum but a penalty clause? *Journal of law and commerce* (Pittsburgh, Pa.) 30:2:173-184, 2012.
- Zhou, Qi. CISG versus English Sales Law: an unfair competition. *Social science research network* October 10, 2011. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://ssrn.com/abstract=1941845>.

III. Arbitraje y conciliación comercial internacional

- Ababneh, A. y S. Alkasawneh-Jordan. The relationship between arbitration and jurisdiction within Europe post the West Tankers case. *Business law review* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 33:4:82-86, 2012.
- Actas de la conferencia titulada «Traités internationaux relatifs au droit du commerce» 25 de noviembre de 2009, Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo. S.l., s.n., 2011. 67 páginas. Contenidos seleccionados: Madagascar: le droit de l'arbitrage et l'application de la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales / R. Jakoba, páginas. 25 a 33.
- Al-Hawamdeh, A. M. The effect of the Rome I Regulation upon the choice of non-state law and 'amiable composition' by parties in arbitration. *Business law review* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 33:5:116-119, 2012.
- Ali, S. F. y Tom Ginsburg, editores. International commercial arbitration in Asia. 3ª ed. Huntington, N.Y., Juris, 2013. 634 páginas.
- Amro, I. Review of a foreign arbitral award by national courts: a comparative study in common law and civil law countries. *Hague yearbook of international law = Annuaire de La Haye de droit international* (Leiden, Países Bajos) 24:391-413, 2012.

- _____. The refusal of recognition and enforcement of a foreign arbitral award under the New York Convention of 1958: a comparative study in common law and civil law countries. *Vindobona journal of international commercial law and arbitration* (Viena) 15:2:365-388, 2011.
- Ashcroft's \$40 mil arbitration award against GOB not enforceable, rules Court of Appeal. *Amandala newspaper* (Ciudad de Belice, Belice) 9 de agosto de 2012.
- Atabayev, A. y M. Dosov. Автономия арбитражной оговорки и принцип «компетенции компетенции» в международной практике. *Юрист* (Алматы) 12, 2012.
- Baamir, A. Y. The new Saudi Arbitration Act: evaluation of the theory and practice. *International arbitration law review* (Londres) 15:6:219-235, 2012. El artículo incluye la versión en inglés de la ley.
- Bán, D. y L. Kecskés. Changing aspects of unsigned arbitration agreements. *Czech (& Central European) yearbook of arbitration* (Huntington, N.Y.) 2:107-132, 2012.
- Bardina, M. Международный коммерческий арбитраж: свобода в выборе применимого права. *Корпоративный юрист* (Москва) 12:6:24-28, 2012. Traducción del título: Arbitraje comercial internacional: libertad de elección de la ley.
- Baskaran, T. Recent amendments to the Malaysian Arbitration Act. *Arbitration international* (Londres) 28:3:533-543, 2012.
- Bazinas, S. V. Ο Πρότυπος Νόμος για τη Συμβιβαστική Επίλυση Διαφορών της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. *Bulletin of Sociétés Anonymes and limited liability companies* (Atenas) 503-506, 1 de noviembre de 2006. Traducción del título: Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.
- Bělohávek, A. J. Ochrana konsumentů w postępowaniu arbitrażowym. Varsovia, Beck, 2012. 605 páginas. Traducción del título: Protección de los consumidores en el arbitraje.
- Benedettelli, M. V. 'Pensiero debole' nell'arbitrato commerciale internazionale e comunitarizzazione del diritto dell'arbitrato. *Diritto del commercio internazionale* (Génova, Italia) 26:2:305-325, 2012. Traducción del título: 'El pensamiento débil' en el arbitraje comercial internacional y la comunitarización del derecho de arbitraje.
- Berg, A. J. van den, ed. Arbitration: the next fifty years. Alphen aan den Rijn, Países Bajos, Wolters Kluwer, 2012. 300 páginas.
- Beyneix, I. y L-C. Lemmet. L'arbitrage international est-il encore véritablement un mode alternatif de règlement des différends? *Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique* (París) 2:225-243, 2012.
- Bhatia, V. K. y otros, editores. Discourse and practice in international commercial arbitration: issues, challenges and prospects. Farnham, Reino Unido, Ashgate, 2012. 322 páginas.

- Bird, R. C. Enforcement of annulled arbitration awards: a company perspective and an evaluation of a 'new' New York Convention. *North Carolina journal of international law and commercial regulation* (Chapel Hill, N.C.) 37:1013-1055, 2012.
- Blanke, G. y S. Corm-Bakhos. Enforcement of New York Convention awards: are the UAE courts coming of age? *Arbitration* (Londres) 78:4:359-365, 2012.
- Błaszczak, L. y J. Kolber. Annulment and enforcement of arbitral awards in Poland. *ASA bulletin* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 30:3:564-584, 2012.
- Booz, Allen [y] Hamilton (Nueva York). Reinforcing Ethiopia's international trade law framework for a stronger business environment: a case for the ratifications of the New York Convention and the CISG. S.I., USAID, 2008. 27 páginas.
- Born, G. B. Arbitrability and public policy. *World arbitration & mediation review* (Huntington, N.Y.) 5:3:293-300, 2011.
- _____. International arbitration: law and practice. Alphen aan den Rijn, Países Bajos, Kluwer Law International, 2012. 480 páginas.
- Caprioli, E. A. Arbitrage international et commerce électronique. *Revue Lamy droit de l'immatériel* (Rueil-Malmaison, Francia) 81:114-118, abril de 2012.
- Carminati, G. The optional rules for arbitration of disputes relating to outer space activities: a comparison to the UNCITRAL Rules. *International law journal: Los Angeles County Bar Association* (Los Angeles, Calif.) 1:1, octubre de 2012.
- Casey, J. B. Arbitration law of Canada: practice and procedure. 2nd ed. Huntington, N.Y., Juris, 2011. 466 páginas y 490 páginas. (Apéndices).
- Chan, D. Role of natural justice in the making of an additional award. *Mealey's international arbitration report* (King of Prussia, Pa.) 27:5:26-31, 2012.
- Chang, Seung Wha. Inherent power of the arbitral tribunal to investigate its own jurisdiction. *Journal of international arbitration* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 29:2:171-182, 2012.
- Chovancová, K. Enforcement procedures in selected European countries. *Transnational dispute management* (Voorburg, Países Bajos) 9:4, agosto de 2012.
- Correll, C. C. y R. J. Szczepanik. No arbitration is an island: the role of courts in aid of international arbitration. *World arbitration & mediation review* (Huntington, N.Y.) 6:3:565-618, 2012.
- Czernich, D. Die Bestimmung des auf die Schiedsvereinbarung anzuwendenden Rechts in Liechtenstein. *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft* (Heidelberg, Alemania) 111:4:428-441, 2012. Traducción del título: La ley aplicable al convenio de arbitraje en Liechtenstein.
- Daele, K. Challenge and disqualification of arbitrators in international arbitration. Alphen aan den Rijn, [Países Bajos], Kluwer Law International, 2012. 539 páginas.

- Damson, S. G. Enforcing international arbitration agreement: has the model law affected the need for anti-suit injunction? *CAR: CEPMLP annual review* (Dundee, Escocia) 2009/2010.
- Dias Simões, F. Macau: a seat for Sino-Lusophone commercial arbitration. *Journal of international arbitration* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 29:4:375-389, 2012.
- Dorda, C. y V. Öhlberger. Vienna perspective: 2012. *Mealey's international arbitration report* (King of Prussia, Pa.) 27:3:26-37, 2012.
- Douglas, J. Arbitration of international sale of goods disputes under the Vienna Convention. *Arbitrator & mediator* (Melbourne) 27:1:15-24, 2008.
- Draetta, U. La Convention des Nations Unies de 1980 sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises et l'arbitrage = The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and arbitration. *Revue de droit des affaires internationales = International business law journal* (París) 2:193-205, 2012.
- Drahozal, C. R. The New York Convention and the American Federal System. *Social science research network* May 26, 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://papers.ssrn.com/abstract=2101396>.
- Ege, E. The unclear role yet inevitable application of domestic law under Energy Charter Treaty arbitration = L'application inévitable du droit national dans le cadre de l'arbitrage du Traité sur la Charte de l'Energie. *Revue de droit des affaires internationales = International business law journal* (París) 2:173-191, 2012.
- El Ahdab, J. y M. Eid. An overview of the new Saudi Arbitration Act: a smooth evolution but no revolution. *Mealey's international arbitration report* (King of Prussia, Pa.) 27:10:18-21, 2012.
- Esplugues Mota, C. La aplicación del Convenio de Nueva York de 1958 por parte de los tribunales españoles. En "Arbitraje comercial y arbitraje de inversión." C. A. Soto Coaguila, ed. Lima, Instituto Peruano de Arbitraje/Manga Ediciones, 2009. Páginas. 291 a 335.
- _____. Validity and effects of the incorporation by reference of arbitration agreements in international maritime arbitration: current situation and future trends. *Diritto del commercio internazionale* (Genova, Italia) 26:2:371-402, 2012.
- Fan, Kun. The new Arbitration Ordinance in Hong Kong. *Journal of international arbitration* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 29:6:715-722, 2012.
- Farhad, A. y M. Purice. An introduction to the Dubai International Financial Centre: a jurisdiction within a jurisdiction. *Revista română de arbitraj* (Bucurest) 25:1:67-74, 2013.

- Favalli, D. y otros, editores. Documentos seleccionados sobre arbitraje internacional. Berna, Stämpfli, 2011. 129 páginas. The protection of business secrets in international commercial arbitration / L. F. Wyss — Respondent's refusal to pay the advance on costs: the contractual and the procedural approach / P. Sieber — Suspensive effect of an appeal against an arbitral awards in Switzerland / E. Rappold Müller — Recognition/enforcement of annulled awards under special consideration of the Amsterdam Court of Appeals' decision of 28 April 2009 / M. C. Lerch.
- Fénéon, A. Le projet de loi sur la médiation au Burkina Faso: premice d'un droit africain de la médiation. *Penant: revue trimestrielle de droit africain* (París) 122:881:425-439, 2012.
- De Fina, A. A. Public policy and arbitration in Australia. *Arbitrator & mediator* (Melbourne) 31:1:77-96, 2012.
- _____. Swings and roundabouts: developments in arbitration in Australia. *Mealey's international arbitration report* (King of Prussia, Pa.) 27:5:19-25, 2012.
- Fong, D. e I. Che. Enforcement of foreign arbitral awards in Vietnam. *Asian dispute review* (Hong Kong) 90-93, julio de 2012.
- Galloway, P. D. Using experts effectively and efficiently in arbitration. *Dispute resolution journal* (Nueva York) 67:3:27-34, 2012.
- German Institution of Arbitration. UNCITRAL Arbitration Rules: administered by the DIS (vigentes a partir del 1 de mayo de 2012). Colonia, DIS, 2012. 1 vol.
- Gorskie, J. L. US courts and the anti-arbitration injunction. *Arbitration international* (Londres) 28:2:295-323, 2012.
- Graves, J. Court litigation over arbitration agreements: is it time for a new default rule? *American review of international arbitration* (Nueva York) 23:113-137, 2012.
- Greenberg, S. y otros. International commercial arbitration: an Asia-Pacific perspective. Cambridge [Reino Unido], Cambridge University Press, 2011. 543 páginas.
- Grenig, J. E. International commercial arbitration. Eagan, Minn., West, 2011. 241 páginas.
- Gu, Weixia. Modern arbitration agreement as threshold of globalization under the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. *Arbitrator & mediator* (Melbourne) 27:1:41-55, 2008.
- Guo, Ping y Han Deng. Toward internationalization: recent developments in repeal and non-enforcement of arbitral awards in China. *Asian business lawyer* (Seúl) 10:115-135, 2012.
- Gupta, S. Injunction raj: whether anti-arbitration injunctions are a threat to international arbitrations in India. *International arbitration law review* (Londres) 15:1:1-11, 2012.
- Gyarfas, J. Constitutional scrutiny of arbitral awards: odd precedents in Central Europe. *Journal of international arbitration* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 29:4:391-403, 2012.

- Habegger, P. The revised Swiss Rules of International Arbitration: an overview of the major changes. *ASA bulletin* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 30:2:269-311, 2012.
- Halket, T. D., editores. Arbitration of international intellectual property disputes. Nueva York, Juris, 2012. 618 páginas. Contenidos seleccionados: Ch. 4. The rules of selected administrative bodies relevant to intellectual property disputes / F. L. Politano — Ch. 7. Disclosure and admission of evidence in the international arbitration of intellectual property disputes / J. P. Zammit, T. R. Hambidge y Jamie Hu — Ch. 11. Enforceability / T. Calame y M. Aebi.
- He, Qisheng y Dayong Zhou. Prospective UNCITRAL technical assistance for Asian countries in international arbitration. *Asian business lawyer* (Seúl) 11:93-104, 2011.
- Heintzman, T. G. The new Canada-China Foreign Investment Agreement: will the UNCITRAL Arbitration Rules result in enforceable justice? *JD supra* (Sausalito, Calif.) 7 de octubre de 2012.
- Hill, J. The significance of foreign judgments relating to an arbitral award in the context of an application to enforce the award in England. *Journal of private international Law* (Oxford, Reino Unido) 8:2:159-193, 2012.
- Holmes, M. The importance of the seat of an arbitration under the new uniform commercial arbitration legislation in Australia. [Conferencia] A modern legal framework to enable global trade: the new legislation on arbitration and on electronic transactions, the University of Queensland Australia, TC Beirne School of Law, Brisbane, Australia, 5 de febrero de 2013. Ponencia.
- Holmes, M. y C. Brown. The international arbitration act 1974: a commentary. Chatswood, N.S.W., Lexis Nexis Butterworths, 2011. 349 páginas.
- Johnson, L. Inching towards consensus: an update on the UNCITRAL transparency negotiations. *Investment treaty news* (Ginebra) 3:1:12, octubre de 2012.
- Júdice, J. M. The new Portuguese Arbitration Law. *ASA bulletin* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 30:1:7-50, 2012. El anexo incluye el texto de la ley en inglés.
- Junita, F. Judicial review of international arbitral awards on the public policy exception in Indonesia. *Journal of international arbitration* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 29:4:405-427, 2012.
- _____. Public policy exception in international commercial arbitration: promoting uniform model norms. *Contemporary Asia arbitration journal* (Taipei) 5:1:45-81, 2012.
- Kachwaha, S. 'Interim relief': comments on the UNCITRAL amendments and the Indian perspective. *Transnational dispute management* (Voorburg, Países Bajos) 9:4, agosto de 2012.
- Kantaria, S. The enforcement of domestic and foreign arbitral awards in the UAE under the Civil Procedure Code and proposed arbitration law. *International arbitration law review* (Londres) 15:2:61-66, 2012.

- Kasolowsky, B. y M. Steup. *Dallah v Pakistan: Umfang und Grenzen der Kompetenz-Kompetenz von Schiedsgerichten*. *IPRax* (Bielefeld, Alemania) 32:2:179-183, 2012. Traducción del título: *Dallah v Pakistán: Alcance y límites del principio Kompetenz-Kompetenz de los tribunales de arbitraje*.
- Kendra, T. La portée internationale des sentences arbitrales annulées dans leur pays d'origine: vers une approche internationale commune? = The international reach of arbitral awards set aside in their country of origin. *Revue de droit des affaires internationales = International business law journal* (París) 1:35-52, 2012.
- Kennedy-Grant, T. The role of arbitration in developing and developed economies and the importance of arbitration systems in attracting foreign direct investment: El papel del arbitraje en los países en desarrollo y desarrollados y la importancia que tienen los sistemas de arbitraje para atraer inversión extranjera directa; ponencia presentada en la conferencia inaugural internacional sobre arbitraje celebrada en Brunei y en la segunda conferencia del RAIF, celebrada el 16 de agosto de 2008. Ponencia.
- Kirby, J. Finality and arbitral rules: saying an award is final does not necessarily make it so. *Journal of international arbitration* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 29:1:119-128, 2012.
- Kleinman, J. y T. Madell. *Avtalsslutande vid internationella köp av varor*. Copenhagen, Consejo Nórdico, 2009. 106 páginas. En sueco. Traducción del título: *Contratación para la venta internacional de mercancías*.
- Knez, R. y M. Djinović. Slovenska arbitražna pravila 2013: pogled v prihodnost. *Slovenska arbitražna praksa* (Ljubljana) 1:1:35-38, 2012. Traducción del título: *Las normas de arbitraje de Eslovenia, 2013: perspectivas futuras*.
- Kröll, S. The non-enforceability of decisions rendered in summary arbitral proceedings pursuant to the NAI Rules under the New York Convention. *American review of international arbitration* (Nueva York) 23:75-112, 2012.
- Kröll, S. y otros, editores. *International arbitration and international commercial law: synergy, convergence and evolution*, [liber amicorum Eric Bergsten]. Alphen aan den Rijn, Países Bajos, Kluwer Law International, 2011. 842 páginas. Contenidos seleccionados: The UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings: time for an update? / P. A. Habegger, A. von Mühlendahl — (In)appropriate compromise: article 16(3) of the Model Law and its progeny / V. Pavić — Can proceeding 'not in accordance with the agreement of the parties' be condoned? Remarks on article V(1)(d) of the New York Convention / T. Várady.
- Kryvoi, Y. Counterclaims in investor-state arbitration. *Minnesota journal of international law* (Minneapolis, Minn.) 21:2:216-252, 2012.
- Kuo, Houchih. Refusal of Taiwanese Court to recognize ad hoc arbitration: implications and the future of ad hoc arbitration in Taiwan. *Asian dispute review* (Hong Kong) 59-62, abril de 2012.
- Kushelev, P. An international approach to breaking the core of the Bankruptcy Code and FAA conflict. *Emory bankruptcy development journal* (Atlanta, Ga.) 28:355-392, 2012.

- Lazić, V. The Commission's proposal to amend the arbitration exception in the EC jurisdiction regulation: how 'much ado about nothing' can end up in a 'comedy of errors' and in anti-suit injunctions Brussels-style. *Journal of international arbitration* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 29:1:19-47, 2012.
- Lee, Junsang. Korean courts' attitude and practice in relation to arbitration. *Korean arbitration review* (Seúl) 1:26-28, 2012.
- Lembo, S. The 1996 UK Arbitration Act and the UNCITRAL Model Law: a contemporary analysis. Roma, LUISS, 2011. 216 páginas. Tesis (PhD) — Università LUISS Guido Carli, Facultad de Derecho, 2010.
- Liang, Jiaqi. The enforcement of mediation settlement agreements in China. *American review of international arbitration* (Nueva York) 19:489-519, 2008.
- Liber amicorum Abascal: part I. *World arbitration & mediation review* (Huntington, N.Y.) 6:1:1-168, 2012. Journal section. Contenidos seleccionados: Introduction and dedication to the liber amicorum José María Abascal / L. E. Graham, P. Perales Viscasillas, A. Sabater, páginas 1 a 6 — UNCITRAL Rules and Model Law — Generalizing about the virtues of specificity: the surprising evolution of the longest article in the UNCITRAL Model Law / J. Castello, páginas 7 a 34 — Ad hoc international arbitrations: the way of the future? / C. M. Baker, E. C. Olivares, páginas 35 a 50 — International arbitration in Mexico — From the abstract to reality: challenges in recognizing and enforcing commercial arbitration awards in Mexico / L. O. Guerrero Rodríguez, X. Suárez Enríquez, páginas 51 a 78 — The Mexico City National Chamber of Commerce Commercial Arbitration and Mediation Commission / Y. Quiroz Valdovinos, páginas 79 a 96 — Mexico's amendment to facilitate judicial cooperation in arbitration / R. Zamora, páginas 97 a 104 — Equity and culture: analyzing perspectives — Ex aequo et bono arbitration — G. Lozano Alarcón, páginas 105 a 124 — 'Cultural conflicts' in international arbitration: myths, misunderstandings, and lessons from dealing with the unusual / A. Sabater, páginas 125 a 138 — Insolvency proceedings: international law's answer to a world crisis — Arbitration as a tool in support of insolvency procedures (concurso mercantil) / T. S. Heather, páginas 161 a 168.
- Lowther, J. Analysis of the effect of Tajikistan's future ratification of the New York Convention. Almaty, USAID, 2007. 20 páginas.
- De Ly, F. y otros. International Law Association International Commercial Arbitration Committee's report and recommendations on 'confidentiality in international commercial arbitration'. *Arbitration international* (Londres) 28:3:355-396, 2012.
- Madrid Parra, A. UNCITRAL in favor of using electronic means in arbitration. *World arbitration & mediation review* (Huntington, N.Y.) 6:2:275-297, 2012.
- Magnusson, A. The SCC experience of investment arbitration under the UNCITRAL Rules. *SCC newsletter* (Estocolmo) 2012:11.
- Mahajan, K. y M. Anand. Heralding a new dawn for arbitration in India: is there reason to be circumspect any more? *Arbitration* (Londres) 79:1:28-36, 2013.

- Malaysia. Attorney General's Chambers. Judicial interpretation on the public policy exception to the enforcement of arbitral award. *Blog Rasmi Jabatan Peguam Negara* (Kuala Lumpur) 27 de junio de 2012.
- Malheiro, G. y P. Sousa Uva. Portugal finally approves its new arbitration law = Portugal adopte finalement ses nouvelles lois d'arbitrage. *Revue de droit des affaires internationales = International business law journal* (París) 3:327-348, 2012.
- Mandaloniz, M. G. No es oro todo lo que reluce en las microfinanzas: la necesidad de una regulación internacional. *Revista de derecho bancario y bursátil* (Valladolid, España) 127:103-159, 2012.
- Mante, J. e I. Ndekugri. Arbitrability in the context of Ghana's new arbitration law. *International arbitration law review* (Londres) 15:2:31-41, 2012.
- Mantilla-Serrano, F. Algunos apuntes sobre la ejecución de los laudos anulados y la Convención de Nueva York. *Revista colombiana de derecho internacional* (Bogotá) 15:15-40, 2009.
- Marian, C. Proper notice: common problems in interpreting Article V(1)(b) of the New York Convention in light of the Lernmorniiproekt Decision of the Swedish Supreme Court. *Arbitration international* (Londres) 28:3:545-566, 2012.
- Martínez, S. D. Interaction between courts and arbitrators in Uruguay. *Arbitration international* (Londres) 28:4:757-768, 2012.
- Menétrey, S. La transparence dans l'arbitrage d'investissement. *Revue de l'arbitrage* (París) 1:33-64, 2012.
- Menezes, R. Is the role of the appointing authority in the appointment of arbitrators under the (Indian) Arbitration and Conciliation Act, 1996, different from the role of appointing authorities in the general practice of international arbitration? *CAR: CEPMLP annual review* (Dundee, Escocia) 2007.
- Milner, A. y R. D'Cruz. Advantages and disadvantages of arbitrating CIS disputes in Western Europe. *Transnational dispute management* (Voorburg, Países Bajos) 9:3, abril de 2012.
- Mohtashami, R. y M. Lawry-White. The (non)-application of the New York Convention by the Qatari courts: *ITHIC v. Dyncorp*. *Journal of international arbitration* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 29:4:429-436, 2012.
- Monichino, A. Arbitration law in Victoria comes of age. *Arbitrator & mediator* (Melbourne) 31:1:41-64, 2012.
- Moreno Rodríguez, J. A. Contracts and non-state law in Latin America. *Uniform law review = Revue de droit uniforme* (Roma) 16:4:877-889, 2011.
- Moser, M. J. y J. Choong, editores. Asia arbitration handbook. Oxford, Reino Unido, Oxford University Press, 2011. 1197 páginas.
- Muranov, A. I. y L. S. Baleevskikh. The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Russia: implementation and procedural mechanisms to make it operative: a general survey. *Вестник международного коммерческого арбитража* (Москва) 1:58-72, 2010.

- Naciones Unidas. UNCITRAL 2012 digest of case law on the Model Law on International Commercial Arbitration. Nueva York, Naciones Unidas, 2012. 232 páginas. También disponible en CD-ROM. Puede consultarse en línea en la dirección: www.uncitral.org/uncitral/en/publications/publications.html.
- Nakamura, Tatsuya. The recent Japanese court decisions on arbitration. *JCAA newsletter* (Tokio) 28:4-10, 2012.
- Nappert, S. Commentary on the UNCITRAL Arbitration Rules 2010: a practitioner's guide. Huntington, N.Y., JurisNet, LLC, 2012. 214 páginas.
- Natov, N. The autonomy of arbitrators in determining the law applicable to the merits of a case. *Czech (& Central European) yearbook of arbitration* (Huntington, N.Y.) 2:171-190, 2012.
- Nell, G. Recent developments in the enforcement of foreign arbitral awards in Australia. *Australian & New Zealand maritime law journal* (Murdoch, Australia) 26:1:24-68, 2012.
- Nomura, Yoshiaki. 外国仲裁判断の承認と執行—ニューヨーク条約か2国間条約か. *Documento de debate de la OSIPP* (Osaka, Japón) DP-2011-J-008, 2011. En japonés. Traducción del título: Reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros: relación entre la Convención de Nueva York y los tratados bilaterales en el Japón.
- Nottage, L. International commercial arbitration developments in model law jurisdictions: Japan seen from Australia. *JCAA newsletter* (Tokio) 29:3-11, 2012.
- Nowaczyk, P. New UNCITRAL Arbitration Rules. *Revista română de arbitraj* (Bucurest) 23:3:16-20, 2012.
- O'Brien, P. Discurso de fondo pronunciado ante la Conferencia internacional sobre arbitraje, celebrada en Balaclava (Mauricio) el 10 de diciembre de 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: http://untreaty.un.org/ola/media/info_from_lc/Keynote%20Speech%20-%20Mauritius%20International%20Arbitration%20Conference.pdf.
- O'Malley, N. D. Rules of evidence in international arbitration: an annotated guide. Londres, Informa, 2012. 381 páginas.
- Olatawura, O. O. Nigeria's appellate courts, arbitration and extra-legal jurisdiction: facts, problems, and solutions. *Arbitration international* (Londres) 28:1:63-76, 2012.
- _____. Stay of proceedings in Nigerian law of arbitration: an analysis of its functions, applications and problems. *Arbitration international* (Londres) 28:4:689-720, 2012.
- Onyema, E. The new Ghana ADR Act 2010: a critical overview. *Arbitration international* (Londres) 28:1:101-124, 2012.

- Özsunay, E. y M. R. Özsunay. Arbitration in Turkey: an analysis of Turkish arbitration legislation in light of the UNCITRAL Model Law. *ICC International Court of Arbitration bulletin* (París) 22:2:15-30, 2011.
- _____. International arbitration and mediation in Turkey. *Croatian arbitration yearbook* (Zagreb) 19:209-238, 2012.
- Patocchi, P. M. y P. Marzolini. I terzi ed il procedimento arbitrale nella prospettiva internazionale. *Rivista dell'arbitrato* (Milano) 22:4:783-798, 2012. Traducción del título: Terceros en el procedimiento de arbitraje desde una perspectiva internacional.
- Paulsson, M. R. P. The New York Convention: can we finally move forward from 1958 to 1953? *European international arbitration review* (Huntington, N.Y.) 1:1:1-17, 2012.
- Peiris, N. UNCITRAL arbitration culture in Sri Lanka after Bino Tyres. *International arbitration law review* (Londres) 15:5:N-37-N-39, 2012.
- Perales Viscasillas, M. P. y I. Torterola, editores. Nuevo Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI 2010 anotado y comentado por materias y antecedentes legislativos. Buenos Aires, Legis Argentina, 2011. 510 páginas.
- Piers, M. Consumer arbitration and European private law: a seminal consumer arbitration model law for Europe. *European review of private law = Revue européenne de droit privé = Europäische Zeitschrift für Privatrecht* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 21:1:247-288, 2013.
- Pinkston, J. y otros. Jurisdictional requirements for the enforcement of arbitral awards against defendants and their ownership interest in subsidiaries: a comparative review. *International arbitration law review* (Londres) 15:3:97-117, 2012.
- Poon, N. Striking a balance between public policy and arbitration policy in international commercial arbitration: *AJU v. AJT*. *Singapore journal of legal studies* (Singapur) 185-195, 2012.
- Pullé, A. I. Arbitration law developments in Singapore. *Comparative law yearbook of international business* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 33:3-44, 2011.
- Rahman, A. J. Developments in arbitration and mediation as alternative dispute mechanisms in Brunei Darussalam. [Conferencia] A modern legal framework to enable global trade: the new legislation on arbitration and on electronic transactions, the University of Queensland Australia, TC Beirne School of Law, Brisbane, Australia, 5 de febrero de 2013.
- Rai, S. Proposed amendments to the Indian Arbitration Act: a fraction of the whole? *Journal of international dispute settlement* (Oxford) 3:1:169-204, 2012.
- Rajoo, S. Introduction: the Asia-Pacific arbitration review 2012. *APRAG newsletter* (Kuala Lumpur) julio – diciembre de 2011.
- Rau, A. S. The errors of COMITY: forum non conveniens returns to the second circuit. *American review of international arbitration* (Nueva York) 23:1-49, 2012.

- Raviv, A. No more excuses: toward a workable system of dispositive motions in international arbitration. *Arbitration international* (Londres) 28:3:487-509, 2012.
- Regional conference on 'harmonization of the law: the Hague Conference, Unidroit and UNCITRAL': Beirut Arab University, [10 y 11 de septiembre 2012], Beirut, Lebanon [textos de conferencia]. Beirut, Beirut Arab University, 2012. CD-ROM. Contenidos seleccionados: The adoption of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: a step towards the harmonization of the Arab laws / Omar M.H. Aljazy. En árabe, francés e inglés.
- Rigdon, D. y A. V. Salzillo. Civil practice: arbitration. *Georgia State University law review* (Atlanta, Ga.) 29:334-352, 2012.
- Rijavec, V. Začasne odredbe v arbitražnem postopku. *Slovenska arbitražna praksa* (Ljubljana) 1:1:9-17, 2012. Traducción del título: Medidas provisionales en el procedimiento de arbitraje.
- Roodt, C. Autonomy and due process in arbitration: recalibrating the balance. *Comparative and international law journal of Southern Africa* (Pretoria) 44:3:311-339, 2011.
- Rost, J. y otros. Comparative international perspectives of arbitration in the franchising context. *Franchise law journal* (Chicago, Ill.) 31:3:124-129, 2012.
- Sami ud-Din, Mian. International commercial arbitration: developments in the practice of taking evidence. *Arbitration* (Londres) 79:1:17-27, 2013.
- Sander, A. Investment insurance and investment arbitration: the position of the third party. *European international arbitration review* (Huntington, N.Y.) 1:1:19-29, 2012.
- Șandru, D-M. y A. Săvescu, editores. Forța juridică a hotărârilor arbitrale = The binding nature of arbitral award. București, Editura Universitară, 2012. 345 p. Contenidos seleccionados: Relația dintre locul arbitrajului și calificarea unei hotărâri arbitrale ca fiind națională sau străină / C. Leaua — Arbitration in Brazil: a critical overview / K. Noussia — Recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine / S. Dinescu. En inglés y rumano.
- Schwarz, D. M. U.S. statutory rights and public policy under the Federal Arbitration Act and the New York Convention in international disputes. *New York international law review* (Albany, N.Y.) 25:2:1-17, 2012.
- Soto Coaguila, C. A. y O. C. Espinoza Soto, editores. Convención de Nueva York de 1958 reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Lima, Instituto Peruano de Arbitraje, 2009. 900 páginas.
- Steingruber, A. M. Consent in international arbitration. Oxford, Oxford University Press, 2012. 366 páginas.
- Stotter, H. J., ed. Das neue liechtensteinische Schiedsverfahrensrecht (SchVR). Triesen, Liechtenstein, Ritter Verlagsanstalt, 2012. 234 páginas. Traducción del título: La nueva ley de arbitraje de Liechtenstein.

- Strong, S. I. Border skirmishes: the intersection between litigation and international commercial arbitration. *Social science research network* 25 de abril de 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://papers.ssrn.com/abstractd=2046219>.
- _____. International commercial arbitration: a guide for U.S. judges. Washington, D.C., Federal Judicial Center, 2012. 143 p. Puede consultarse en línea en la dirección: [www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/strongarbit.pdf/\\$file/strongarbit.pdf](http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/strongarbit.pdf/$file/strongarbit.pdf).
- _____. Monism and dualism in international commercial arbitration: overcoming barriers to consistent application of principles of public international law. *Social science research network* 15 de diciembre de 2012. Puede consultarse en línea en la dirección <http://papers.ssrn.com/abstract=2189905>.
- _____. Navigating the borders between international commercial arbitration and U.S. federal courts. *Social science research network* 25 de abril de 2012. Puede consultarse en línea en la dirección <http://ssrn.com/abstract=2046225>.
- Sturini, A. y L. Hui. Commentary on the arbitration rules of the China International Economic and Trade Arbitration Commission. *Vindobona journal of international commercial law and arbitration* (Viena) 15:2:267-288, 2011.
- Style, C. y S. Balthasar. Enforcing international arbitral awards: pitfalls and strategies. *Dispute resolution international* (Londres) 6:1:3-15, 2012.
- Tang, Zheng Sophia. Parallel proceedings and anti-arbitration injunction. *Journal of business law* (Londres) 7:589-610, 2012.
- Thadikkaran, M. Judicial intervention in international commercial arbitration: implications and recent developments from the Indian perspective. *Journal of international arbitration* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 29:6:681-690, 2012.
- The arbitration review of the Americas 2012. Londres, Global Arbitration Review, 2012. 1 vol. Contenidos seleccionados: Introduction / L. M. Martínez — The new ICC and UNCITRAL rules: focus on cost-effectiveness and multiparty disputes / G. Hanessian, D. J. Hayden, J. T. de Paiva Muniz — Argentina / B. A. Irriberri — Bolivia / A. Moreno Gutiérrez — Brasil / A. Wald — Canadá / T. J. Coates, M. D. Schafler, C. Snider — Ecuador / R. Jijón-Letort, J. M. Marchán — Venezuela / F. Peláez-Pier, J. G. Torrealba.
- The Asia-Pacific arbitration review 2012. Londres, Global Arbitration Review, 2012. 1 vol. Contenidos seleccionados: Introduction / S. Rajoo — Comparative arbitration law in Asia / Chong Yee Leong, Qin Zhiqian — Out with the old, in with the new / J. Kwan, Haig Oghigian — Australia / D. Jones — Hong Kong / C. Hassall, K. Sanger — Japan / Yoshimi Ohara — Malaysia / Chong Yee Leong — Singapore / Alvin Yeo, Chou Sean Yu — South Korea / B. Hughes, Beomsu Kim.

- The European & Middle Eastern arbitration review 2012. Londres, Global Arbitration Review, 2012. 1 vol. Contenidos seleccionados: Introduction / M. Abdel Raouf — Lost in translation? The independence of experts under the 2010 IBA Rules / J. Barratt — Austria / B. H. Steindl — Belgium/J. Billiet, D. Nigmatullina — República Checa / M. Olík — Finlandia / J. Lehtinen, H. Yildiz — Francia / T. Portwood — Italia / F. Emanuele, M. Molfa — Países Bajos / K. Nijburg, B. van der Bend — Omán /A. El Nafie — Polonia / M. Jamka, A. Wojciechowska — Rumania / C. Leaua — Rusia / A. Khrenov, A. Yukov — España / F. J. Montero Muriel — Suiza/ E. Geisinger, A. M. Petti — Turquía — Ucrania / M. Kliuchkovskyi, K. Koriukalova, S. Uvarov — Reino Unido / A. Sheppard.
- The quality of legal acts and its importance in contemporary legal space, 4 a 5 de octubre de 2012. Riga, University of Latvia Press, 2012. 683 páginas. Contenidos seleccionados: ‘Same’ act — different scope: the ‘International [Arbitration]’ criterion in the arbitration laws of the Eurasian UNCITRAL Model Law — compliant jurisdictions / L. Guglya, páginas 477 a 488 — The quality of part 78 of the Latvian Civil Procedure Law and its importance in recognizing and enforcing the foreign arbitral awards / I. Kačevska, páginas 489 a 496 — A new law: a new chance for arbitration in Georgia / S. Tkemaladze, páginas 665 a 673.
- Thomas, N. New York Convention on Recognition of Enforcement of Arbitral Awards 1958: a critical analysis. *JurisOnline* (Gurgaon, India) 20 de mayo de 2012.
- Timmer, L. J. E. The quality, independence and impartiality of the arbitrator in international commercial arbitration. *Arbitration* (Londres) 78:4:348-358, 2012.
- Trakman, L. E. Ex aequo et bono: basing decisions on that which is just and fair. *Transnational dispute management* (Voorburg, Países Bajos) 9:3, abril de 2012.
- Trari-Tani, M. L’arbitrage commercial international: avec référence du droit et à la pratique des pays du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie). Bruselas, Bruylant, 2011. 358 páginas.
- Tsirides, C. y E. Georgiades. Arbitration and mediation in Cyprus. *Dispute resolution journal* (Nueva York) 67:3:84-88, 2012.
- Uzelac, A. Autonomy of the parties and autonomy of the arbitators: supremacy vs. collaboration. *Slovenska arbitražna praksa* (Ljubljana) 1:1:26-34, 2012.
- Valletta, C. V. y D. E. Miller. Spotlight on the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. *New York international chapter news* (Nueva York) 17:1:13-17, 2012.
- Vásquez Palma, M. F. Revisión de las sedes atractivas en el arbitraje comercial internacional: un análisis comparado de los marcos normativos de Suiza, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España, China y Chile. *Revista Chilena de derecho privado* (Santiago) 18:9-94, 2012.
- Wade, G. Courts and arbitration: an Irish perspective. *Arbitration* (Londres) 79:1:37-51, 2013.

- Wagner, K. R. The perfect circle: arbitration's favors become its flaws in an era of nationalization and regulation. *Pepperdine dispute resolution law journal* (Malibu, Calif.) 12:159-188, 2012.
- Walker, S. P. e I. K. Clark. Pleading in arbitration: a practitioner's guide. Edimburgo, Reino Unido, W. Green, 2012. 388 páginas.
- Walters, G. L. Fitting a square peg into a round hole: do res judicata challenges in international arbitration constitute jurisdictional or admissibility problems? *Journal of international arbitration* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 29:6:651-680, 2012.
- Wang, Yuan. Setting aside foreign arbitral awards on procedural grounds: under the influence of Chinese civil procedure law. *International arbitration law review* (Londres) 15:3:81-86, 2012.
- Weeramantry, J. R. Recent developments in Hong Kong arbitration law. *JCAA newsletter* (Tokio) 29:11-15, 2012.
- Weeramantry, R. Setting aside under Article 34 of the UNCITRAL Model Law: new limitations on court and arbitrator discretion in Hong Kong? *Asian dispute review* (Hong Kong) 55 -58, abril de 2012.
- Wells, Aaron L. When 'yes' means 'no': McCarran-Ferguson, the New York Convention, and the limits of Congressional assent. *Pepperdine dispute resolution law journal* (Malibú, Calif.) 12:267-332, 2012.
- Wietzorek, M. Ukrainian courts on agreements to arbitrate in Switzerland. *ASA bulletin* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 30:3:548-563, 2012.
- Von Wobeser, C. The arbitral tribunal's decision to suspend the arbitration. *World arbitration & mediation review* (Huntington, N.Y.) 6:2:299-324, 2012.
- Wolff, R. New York Convention: Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 10 June 1958: commentary. Munich, C.H. Beck, 2012. 613 páginas.
- Yifei, Lin. Judicial review of arbitration agreements in China. *Arbitration international* (Londres) 28:2:243-293, 2012.
- Yoon, Byungchol and Richard Menard. Role of Korean courts in international arbitration. *Korean arbitration review* (Seúl) 1:11-15, 2012.
- Yurieva, M. y A. Anischenko. Recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Belarus: is it really a problem? *Transnational dispute management* (Voorburg, Países Bajos) 9:3, abril de 2012.
- Zachariasiewicz, M. Amicus curiae in international investment arbitration: can it enhance the transparency of investment dispute resolution? *Journal of international arbitration* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 29:2:205-224, 2012.
- Van Zelst, B. The proposed new Dutch Arbitration Act. *International arbitration law review* (Londres) 15:3:75-80, 2012.

Zuberbühler, T. y otros. IBA rules of evidence: commentary on the IBA rules on the taking of evidence in international arbitration. Zurich, Schulthess, 2012. 299 páginas.

IV. Transporte internacional

Actas de la conferencia titulada «Traités internationaux relatifs au droit du commerce», 25 de noviembre de 2009, Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo. S.l., s.n., 2011. 67 páginas. Contenidos seleccionados: Convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (artículo publicado en 2009) / K. Lannan, páginas 49 a 61.

Adyel, K. Crédit documentaire et connaissance. Bruselas, Larcier, 2012. 417 páginas.

Andenas, M. y C. B. Andersen, editores. Theory and practice of harmonisation. Cheltenham, Reino Unido, Edward Elgar, 2011. 617 páginas. Contenidos seleccionados: International law on the carriage of goods by sea: UNCITRAL's most recent harmonisation efforts / M. Goldby.

Berlingieri, F. An analysis of two recent commentaries on the Rotterdam Rules. *Diritto marittimo* (Génova, Italia) 114:1:3-119, 2012.

_____. Uniformità e armonizzazione del diritto marittimo. *Diritto del commercio internazionale* (Génova, Italia) 26:2:445-463, 2012. Traducción del título: Uniformidad y armonización del derecho marítimo.

Cachard, O. La Convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer (Règles de Rotterdam). *Journal du droit international* (París) 139:2:533-569, 2012.

Caprioli, E. A. A propos de la convention de la CNUDCI sur la responsabilité des exploitants de terminaux de transport dans le commerce international. *Annuaire de droit maritime et océanique* (Nantes, Francia) 18:93, enero de 2000.

Conferencia regional titulada 'Harmonization of the law: the Hague Conference, Unidroit and UNCITRAL': Beirut Arab University, [10 y 11 de septiembre de 2012], Beirut, Lebanon [textos de conferencia]. Beirut, Beirut Arab University, 2012. CD-ROM. The Liability of the Sea carrier in accordance with the United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (1978) the 'Hamburg Rules': step from UNCITRAL towards achieving a balance of interests and harmonization of solutions / Faten Hawwa.

Fan, Xiaobo. 2020年的国际海上货物运输法：从海牙时代到鹿特丹时代？. *武大国际法评论* = *International law review of Wuhan University* (Wuhan, China) 15:1:192-212, 2012. Traducción del título: El derecho del transporte marítimo internacional en el año 2020: de la época de La Haya a la época de Rotterdam.

- Force, R. The Regal-Beloit decision: what, if anything, would happen to the legal regime for multimodal transport in the United States if it adopted the Rotterdam Rules. *Tulane maritime law journal* (Nueva Orleans, La.) 36:685-706, 2012.
- Franco, M. Multimodal transport after the Rotterdam Rules: will it work this time? *Journal of international maritime law* (Witney, Reino Unido) 18:3:208-226, 2012.
- Ganesh, S. Indian shipping and international maritime law. *Indian journal of international law* (Nueva Delhi) 51:3:378-407, 2011.
- Giermanski, J. R. The global supply chain and its commercial and security elements. In J. R. Giermanski. *Global supply chain security*. Plymouth, Reino Unido, Scarecrow Press, 2013. Páginas 105-116.
- Girvin, S. *Carriage of goods by sea*. 2ª ed. Oxford, Oxford University Press, 2011. 871 páginas.
- Glass, D. A. *Freight forwarding and multimodal transport contracts*. 2ª ed. Londres, Informa, 2012. 487 páginas.
- Gombrii, K.-J. CMI: champion of the unification of maritime law. *BIMCO bulletin* (Bagsvaerd, Dinamarca) 107:1:64-67, 2012.
- Güner-Özbek, M. D. The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea: an appraisal of the 'Rotterdam Rules'. Springer, Berlín, 2011. 289 páginas.
- Healy, N. J. y otros. *Cases and materials on admiralty*. 5ª ed. St. Paul, Minn., West, 2012. 931. Contenidos seleccionados: Ch. XIII., Section C. The Rotterdam Rules and cargo claims, páginas 901 a 910.
- Herber, R. Die Reform des deutschen Seehandelsrechts: Balance zwischen Rechtsfortbildung und Schifffahrtstradition. *Transportrecht* (Neuwied, Alemania) 35:7:269-276, 2012. Traducción del título: Reforma del derecho marítimo alemán.
- Illescas Ortiz, R. A comment on the arbitration regime under the Rotterdam Rules: a balanced approach. *World arbitration & mediation review* (Huntington, N.Y.) 6:2:245-253, 2012.
- Jha, K. The Rotterdam Rules: should India ratify? *Social science research network 7* de noviembre de 2012. Puede consultarse en línea en la página <http://ssrn.com/abstract=2172335>.
- Lee, D. Y. H. y P. Sookrispaisarnkit. The straight bill of lading: past, present, and future. *Journal of international maritime law* (Witney, Reino Unido) 18:1:39-58, 2012.
- Legros, C. Relations between the Rotterdam Rules and the Convention on the Carriage of Goods by Road. *Tulane maritime law journal* (Nueva Orleans, La.) 36:725-740, 2012.
- Marten, B. Multimodal transport reform and the European Union: a minimalist approach. *European transport law* (Amberes, Bélgica) 47:2:129-152, 2012.

- Ngamkan, G. Etude comparée entre le droit maritime français et le droit maritime communautaire de l'Afrique central (CEMAC). *Droit maritime français* (Paris) 64:738:647-664, 2012.
- Nikaki, T. y B. Soyer. A new international regime for carriage of goods by sea: contemporary, certain, inclusive and efficient, or just another one for the shelves? *Berkeley journal of international law* (Berkeley, Calif.) 30:303-348, 2012.
- Norway. Sjølovkomiteen. Gjennomføring av Rotterdamreglene i sjøloven. Oslo, Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning, 2012. 308 páginas. Incluye el texto de las Reglas de Rotterdam (2008) en noruego. En noruego. Traducción del título: Aplicación de las Reglas de Rotterdam (2008) en el derecho marítimo.
- Reynolds, F. The Hague Rules, the Hague-Visby Rules, and the Hamburg Rules. *Australian and New Zealand maritime law journal* (Auckland, Nueva Zelandia) 7:16-34, 1990.
- Sturley, M. F. Les Règles de Rotterdam à la Conférence de Pékin. *Droit maritime français* (Paris) 65:744:124-129, 2013.
- Thomas, D. R. A comparative analysis of the transfer of contractual rights under the English Carriage of Goods by Sea Act 1992 and the Rotterdam Rules. *Journal of international maritime law* (Witney, Reino Unido.) 17:6:437-451, 2011.
- Treitel, G. H. y F. M. B. Reynolds. Carver on bills of lading. 3rd ed. Londres, Sweet & Maxwell, 2011. 938 páginas. Contenidos seleccionados: Ch. 10. The Rotterdam Rules.

V. Pagos internacionales (incluidas las garantías independientes y las cartas de crédito contingente)

- Australia. Working Group of Officials. National competition policy: review of the Bills of Exchange Act 1909. Canberra, Commonwealth of Australia, 2003. 117 páginas.
- Byrne, J. E. The four stages in the electrification of letters of credit. *George Mason journal of international commercial law* (Arlington, Va.) 3:2:253-279, 2012.
- Castellani, L. G. The role of UNCITRAL texts in promoting a harmonized legal framework for cross-border mobile payments. *Washington journal of law, technology & arts* (Seattle, Wash.) 8:3:265-283, 2013.
- Li, Wen. Finality rules within the law of domestic large value renminbi electronic funds transfers (EFT) in China. Conferencia anual BILETA, 2007, Hertfordshire, [Reino Unido], 16 y 17 de abril de 2007. Ponencia.

VI. Comercio electrónico

- Actas de la conferencia titulada «Traité internationaux relatifs au droit du commerce» 25 de noviembre de 2009, Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo. S.l., s.n., 2011. 67 páginas. Contenidos seleccionados: Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux (artículo publicado en 2006) / J. A. Estrella-Faria, páginas 45 a 47.
- Adamou, M. La valeur de l'écrit électronique dans l'espace UEMOA. *Penant: revue trimestrielle de droit africain* (París) 121:877:502-531, 2011.
- Alzaagy, A. The time of concluding the contract in e-commerce from Islamic legal perspective. *CyberOrient* 6:2, 2012.
- American Bar Association. Section of Business Law. Overview of identity management. Chicago, Ill., ABA, 2012. 20 páginas.
- Andersen, M. B. Rettens digitalisering: aftaleretlige udfordringer. *Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland* (Helsingfors) 4:335-347, 2012. Traducción del título: Dificultades que plantea la digitalización en el derecho contractual.
- Australia. Working Group of Officials. National competition policy: review of the Bills of Exchange Act 1909. Canberra, Commonwealth de Australia, 2003. 117 páginas.
- Berning Prieto, A. D. Derecho de la contratación electrónica. *Oficina San Papeles* 29 febrero 2012.
- Boonnoon, Jirapan. ICT Ministry amending act. *The nation* (Bangkok) 4 de mayo de 2012.
- Byrne, J. E. The four stages in the electrification of letters of credit. *George Mason journal of international commercial law* (Arlington, Va.) 3:2:253-279, 2012.
- Caprioli, E. A. Arbitrage international et commerce électronique. *Revue Lamy droit de l'immatériel* (Rueil-Malmaison, Francia) 81:114-118, abril de 2012.
- Cárdenas, M. J. Debilidades de la normatividad y barreras regulatorias para el desarrollo del comercio electrónico en Colombia. Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 2011. 46 páginas.
- Castellani, L. G. The role of UNCITRAL texts in promoting a harmonized legal framework for cross-border mobile payments. *Washington journal of law, technology & arts* (Seattle, Wash.) 8:3:265-283, 2013.
- _____. The United Nations Electronic Communications Convention: policy goals and potential benefits. *Wuhan University international law review* (Wuhan, China) 14:2:338-348, 2009. En chino. Título original: 《联合国国际合同使用电子通信公约》：政策目标与潜在效益.
- Chan, Wah-Teck. Legal issues in e-commerce and electronic contracting: the Singapore position. Asean Law Association. 8th General Assembly, Singapur, 29 de noviembre a 2 de diciembre de 2003. Ponencia.

- Chung, Chang Ho. Past, current, and future work on electronic commerce. *Asian business lawyer* (Seúl) 7:11-31, 2011.
- Coetzer, F. Dwaling weens foutiewe kommunikasie by die elektroniese kontrakteringsproses. Potchefstroom, North-West University, 2011. 103 páginas Tesis (LL.M.) — North-West University, Potchefstroom Campus, 2011. En afrikaans. Título de la traducción: Error debido a una comunicación defectuosa durante el proceso de contratación electrónica.
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Harmonizing cyberlaws and regulations: the experience of the East African Community. Ginebra, Naciones Unidas, 2012. 58 páginas. Publicación de las Naciones Unidas, UNCTAD/DTL/STICT/2012/4.
- Davidson, A. Adoption of the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts: a critique. [Conferencia] A modern legal framework to enable global trade: the new legislation on arbitration and on electronic transactions, the University of Queensland Australia, TC Beirne School of Law, Brisbane, Australia, 5 de febrero de 2013. Ponencia.
- Davies, A. The development of laws on electronic documents and e-commerce transactions. *Parliamentary information and research service* (Ottawa) PRB 00-12E, 20 de diciembre de 2008.
- Dixon, M. y T. Beal. United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005. *AGS commercial notes* (Canberra) 30:1-15, 2009.
- E-commerce and ODR: current status & prospects in the region, Sept. 20-21, 2012, Hankuk University of Foreign Studies, Seúl, República de Corea. Seúl, Hankuk University of Foreign Studies, 2012. 381 páginas. Contenidos seleccionados: The role of Korea for legal unification on international electronic contracts / Kyoungjin Choi, páginas 99 a 105 — Global outlook on the Electronic Communications Convention: prospects for Canadian implementation / J. D. Gregory, páginas 131 a 143 — The global outlook of the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts: the Australian experience / A. Davidson, páginas 168 a 188.
- Electronic transactions ‘e-commerce & e-governance’, Emirates Centre for Strategic Studies and Research, 19 a 20 de mayo de 2009, [Abu Dhabi] [textos de conferencia]. Contenidos seleccionados: Vol. 3. The scope of the federal UAE e-commerce law: is it self defeating? / Y. Omar — Evidentiary value of electronic transactions / M. Zaheeruddin — Electronic commerce legal framework: some lessons from Malaysia / A. B. Munir, S. H. M. Yasin — Electronic transactions order, 2000 of Brunei Darrussalam: an Islamic legal framework input in the validity of electronic contracts / A. R. A. Haqqi.

- García Peña, J. H. Comercio electrónico: Algunas reflexiones en materia de ley aplicable y jurisdicción competente al amparo de la Convención de las Naciones Unidas sobre las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales. Memorias del XV Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Buenos Aires, 3 a 8 de octubre de 2011. Ponencia.
- Gregory, J. D. Uniform Electronic Communications Convention Act: report and uniform act. Ontario, Uniform Law Conference of Canada, 2010. 20 páginas. Ley uniforme adoptada por la Conferencia de la ley uniforme del Canadá como “Ley uniforme de aplicación de la Convención sobre las Comunicaciones Electrónicas”.
- Imbachí Cerón, J. F. La protección del consumidor en el entorno digital. *Revista de derecho de la competencia* (Bogotá) 4:4:405-455, 2008.
- Iuale, C. A. La equivalencia funcional y el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros. *Jornadas argentinas de informática* (Córdoba, Argentina) 41:296-304, 2012.
- Kim, Hyun-Chul. 전자문서 및 전자거래 기본법의 쟁점과 과제. *Inha law review* (Incheon, República de Corea) 15:2:293-322, 2012. Traducción del título: Cuestiones relativas a la Ley marco de documentos electrónicos y comercio electrónico.
- Sistema Económico Latinoamericano. Secretaría Permanente. Fundamentos de la firma digital y su estado del arte en América Latina y el Caribe. Caracas, SELA, 2012. 21 páginas.
- Maradiaga M., J. R. Incongruencia normativa en materia de comercio electrónico. *Tribuna* (Tegucigalpa, Honduras) 29 de septiembre de 2011.
- Mason, S. Electronic signatures in law. 3ª ed. Nueva York, Cambridge University Press, 2012. 371 páginas.
- McCullagh, A. The incorporation of trust strategies in digital signature regimes. Brisbane, Australia, s.n., 2001. 291 páginas. Tesis (PhD) — Queensland University of Technology, 2001.
- _____. The validity and limitations of software agents in contract formation. [Conferencia] A modern legal framework to enable global trade: the new legislation on arbitration and on electronic transactions, the University of Queensland Australia, TC Beirne School of Law, Brisbane, Australia, 5 de febrero de 2013. Ponencia.
- McCullagh, A. y W. Caelli. Non-repudiation in the digital environment. *First Monday* (Chicago, Ill.) 5:8, agosto de 2000.
- Mik, E. K. Evaluating the impact of the UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts on domestic contract law: the Singapore example. *Research Collection School of Law paper* (Singapur) No. 1070, 2012.
- Mills, K. Effective formation of contracts by electronic means: do we need a uniform regulatory regime? World Summit on Information Technology, Túnez, 15 a 18 de noviembre de 2005. Ponencia.

- Mir, F. A. Emerging legal issues of e-commerce in India. *International journal of electronic commerce studies* (Nueva Ciudad de Taipei, Provincia China de Taiwán) 2:2:165-174, 2011.
- Oh, Se-Chang. Artículos en coreano sobre la CIM (1980) y la Convención de las Naciones Unidas sobre las Comunicaciones Electrónicas (2005). S.l., s.n., 2001. 1 v. Contenidos seleccionados: 청약과 관련한 CISG규정하에서 이루어지는 전자통신에 유엔전자협약 적용시 유의사항. 한국무역상무학회 38:3-45, 30 de mayo de 2008. Traducción del título: Información importante sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales (2005) con arreglo a la CIM (1980) — 국제물품매매협약(CISG)에 전자통신협약(CUECIC) 적용시 국제전자계약의 효력발생을 위한 전제조건에 관한 연구. 계명대학교 산업경영연구소 경영경제 4(2):45-81, agosto de 2008. Traducción del título: Condiciones necesarias para dar efectividad a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas (2005) con arreglo a la CIM (1980) -- CUECIC상의 법적 효력을 위한 형식요건에 관한 연구. 계명대학교 산업경영연구소 경영경제 41(1):193-212, febrero de 2008. Traducción del título: Requisitos formales para la fuerza de ley con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas (2005) — 유엔전자통신협약상의 최종규정에 대한 소고. 계명대학교 산업경영연구소 경영경제 42(1):137-163, febrero de 2009.
- Páez Rivadeneira, J. J. La firma electrónica en el Ecuador. Memorias del XV Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Buenos Aires, 3 a 8 de octubre de 2011. Ponencia.
- Pagnoni, A. y A. Visconti. Secure electronic bills of lading: blind counts and digital signatures. *Electronic commerce research* 10:363-388, 2010.
- Peña Valenzuela, D. y otros. Contratación electrónica: ¿es necesaria una convención internacional? *Revista e-mercatoria* (Bogotá) 1:2, 2002.
- Shiels, P. A. An impact evaluation of current UN and EU E-Commerce regulations on English laws and the effectiveness of creating a binding electronic contract within those laws. Edimburgo, Reino Unido, s.n., 2011. 109 páginas. Tesis (masters) — Heriot Watt University, 2011.
- Terent'eva, L. V. Использование электронных сообщений в международных договорах. *Pravo* (Moscú) 2:77-86, 2011.
- Thi Mai Nguyen, Thom y Dzung Thi Thuy Nguyen. E-commerce in AEC: Vietnam's regulatory framework. *Informed counsel* (Hanoi) 17 de febrero de 2012.
- United Nations Network of Experts for Paperless Trade in Asia and The Pacific and others. Electronic single window legal issues: a capacity-building guide. S.l., Naciones Unidas, 2012. 60 páginas.
- Weber, R. H. Legal framework for the single window concept in ASEAN: a successful movement towards trade facilitation in East Asian countries. *Asian journal of law and economics* (Berlín) 2:4, artículo 2, 2011.

VII. Garantías reales (incluidos los créditos por cobrar)

- Affaki, G. L'apport de la Convention CNUDCI sur la cession de créances aux opérations de banque. *Banque & droit* (París) 90:3-25, julio-agosto de 2003.
- Andenas, M. y C. B. Andersen, editores. Theory and practice of harmonisation. Cheltenham, Reino Unido, Edward Elgar, 2011. 617 páginas. Contenidos seleccionados: International harmonisation of credit and security laws: the way forward / N. O. Akseli.
- Bazinas, S. V. y otros. Facilitating a cost-free path to economic recovery: implementing a global uniform international receivables financing law. *Uniform commercial code law journal* (Nueva York) 44:3:277-316, 2012.
- Bazinas, S. V. Multilingualism in UNCITRAL's work on security interests. *Uniform law review = Revue de droit uniforme* (Roma) 17:3:413-423, 2012.
- Beale, H. y otros. The law of security and title-based financing. 2ª ed. Oxford, Oxford University Press, 2012. 821 páginas. Contenidos seleccionados: Ch. 22. Conflict of laws, páginas. 669 a 742.
- British Institute of International and Comparative Law. Study on the question of effectiveness of an assignment or subrogation of a claim against third parties and the priority of the assigned or subrogated claim over a right of another person: final report. Londres, BIICL, 2012. 415 páginas.
- Deschamps, M. La Convention des Nations unies sur la cession de créances dans une perspective canadienne. *Banque & droit* (París) 90:40-43, julio-agosto de 2003.
- Hishinuma, Takeshi. 孤児著作物問題の研究 : 既存規範の動態的な分析と新規範の確立に向けての可能. Tokio, 成文堂, 2011. 288 páginas. En japonés. Traducción del título: Investigación sobre cuestiones relacionadas con derechohabientes no localizables.
- International Securities Consultancy. Islamic Republic of Pakistan: strengthening secured transactions. S.I., Banco Asiático de Desarrollo, 2008. 119 páginas.
- Jon, Woo-Jung. Comparative analysis of the newly enacted Korean Security Rights Registration Act. *Comparative law yearbook of international business* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 33:455-494, 2011.
- Kieninger, E-M. Das auf die Forderungsabtretung anzuwendende Recht im Licht der BIICL-Studie. *IPRax* (Bielefeld, Alemania) 32:4:289-297, 2012. Traducción del título: Legislación aplicable a la cesión de créditos a la luz del estudio del BIICL.
- Kohn, R. M. Convention to bolster exports and jobs: U.N. pact would increase business loans based on receivables. *Washington times* (Washington, D.C.) 6 de marzo de 2012.

- Kröll, S. y otros, editores. International arbitration and international commercial law: synergy, convergence and evolution, [liber amicorum Eric Bergsten]. Alphen aan den Rijn, Países Bajos, Kluwer Law International, 2011. 842 páginas. Contenidos seleccionados: The Principle of Debtor Protection under the UN Convention on the Assignment of Receivables / O. Akseli.
- Leible, S. y M. Müller. Die Anknüpfung der Drittwirkung von Forderungsabtretungen in der Rom I-Verordnung. *IPRax* (Bielefeld, Alemania) 32:6:491-500, 2012. Traducción del título: Efectos frente a terceros de la cesión de créditos en el Reglamento Roma I.
- Mankowski, P. Zessionsgrundstatut v. Recht des Zedentensitzes: ergänzende Überlegungen zur Anknüpfung der Drittwirkung von Zessionen. *IPRax* (Bielefeld, Alemania) 32:4:298-306, 2012. Artículo sobre la cesión de créditos en relación con el Reglamento Roma I.
- Naciones Unidas y otros. Textos sobre garantías reales preparados por la CNUDMI, la Conferencia de La Haya y el UNIDROIT. Comparación y análisis de las principales características de los instrumentos internacionales relacionados con las operaciones garantizadas. Nueva York, Naciones Unidas, 2012. 39 páginas. Publicado en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Puede consultarse en línea en la dirección: www.uncitral.org/uncitral/es/publications/publications.html.
- Sivitanidis, A. Bulk assignment of debts in the conflict of laws. *Revue hellénique de droit international = Hellenic review of international law* (Atenas) 65:1:215-241, 2012.
- Stoufflet, J. L'apport au droit français de la Convention des Nations unies sur la cession de créances dans le commerce international. *Banque & droit* (París) 90:37-39, julio-agosto de 2003.

VIII. Contratación pública

- Baker & McKenzie's global public procurement handbook: 2012 edition, with UNCITRAL's Model Law on Public Procurement with commentary. Chicago, Ill., Baker & McKenzie, 2012. 383 páginas. Contenidos seleccionados: Comentario C. Nicholas, páginas 291 y 292.
- Fairgrieve, D. y F. Lichère, eds. Public procurement law: damages as an effective remedy. Oxford, Hart Publishing, 2011. 239 páginas. Contenidos seleccionados: Remedies for breaches of procurement regulation and the UNCITRAL Model Law on Procurement / C. Nicholas, páginas 213 a 230.
- Green, A. B. International government contract law. Eagan, Minn., West, 2011. 784 páginas.
- Nicholas, C. The 2011 UNCITRAL Model Law on Public Procurement. *Public procurement law review* (Londres) 21:3:NA111-NA123, 2012.
- _____. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2011 года о государственных закупках. *Госзаказ* (Москва) 27:114-123, 2012.

Osuntogun, A. J. Procurement law in Nigeria: challenges in attaining its objectives. *Public procurement law review* (Londres) 21:4:139-152, 2012.

Yukins, C. R. y S. L. Schooner. Incrementalism: eroding the impediments to a global public procurement market. *Georgetown journal of international law* (Washington, D.C.) 38:529-576, 2007.

IX. Insolvencia

Aeschbach Flórez, J. La liquidation forcée des groupes de sociétés. Ginebra, Schulthess, 2012. 440 páginas.

Atkins, S. A. COMI confusion: the imperative for Model Law clarification. *INSOL world* (Londres) cuarto trimestre 2012, páginas 33 y 34.

Bayer, T. Destroying Chapter 15's 'black box'. *Quinnipiac law review* (Hamden, Conn.) 31:85-118, 2013.

Bernardo, P. J. F. Cross-border insolvency and the challenges of the global corporation: evaluating globalization and stakeholder predictability through the UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency and the European Union Insolvency Regulation. *Ateneo law journal* (Makati, Filipinas) 56:799-834, 2012.

Brulard, Y. y F. J. Garcia Martin. International insolvency convention: yearbook 2010, a worldwide overview of the laws ruling the international insolvency. Bruselas, Bruylant, 2011. 484 páginas. Contenidos seleccionados: UNCITRAL models law and third country procedures — UNCITRAL Model Law: cooperation between judges: a British exemple / L. Hawkes – Estados Unidos / W. Simkulak.

Callejas, R. y otros. The Guatemalan cross-border insolvency regime: reviewing the present and foreseeing the future. *INSOL world* (Londres) 27 y 28, primer trimestre 2013.

'Centre of main interests' and the directors' responsibilities in the twilight zone: update on the current work of UNCITRAL Working Group V (insolvency law). *INSOL world* (Londres) tercer trimestre 2012, páginas 37.

Derrington, S. An introduction to cross-border insolvency. *[CMI] Yearbook = Annuaire* (Amberes, Bélgica) 368 a 380, 2011-2012.

Fletcher, I. F. y B. Wessels. A final step in shaping rules for cooperation in international insolvency cases. *International corporate rescue* (Hertfordshire, Reino Unido) 9:5:283-286, 2012.

Ghia, L. y otros. Trattato delle procedure concorsuali. Milano, Wolters Kluwer Italia, 2010. 6 v. Traducción del título: Ensayo sobre los procedimientos de insolvencia.

Halliday, T. C. Architects of the state: international financial institutions and the reconstruction of states in East Asia. *Law and social inquiry* 37:265-293 (2012).

- INSOL International. Cross-border insolvency II: a guide to recognition and enforcement. Londres, INSOL International, 2012. 286 páginas.
- Kröll, S. y otros, editores. International arbitration and international commercial law: synergy, convergence and evolution, [liber amicorum Eric Bergsten]. Alphen aan den Rijn, Países Bajos, Kluwer Law International, 2011. 842 páginas. Contenidos seleccionados: Cross-border insolvency and arbitration: which consequences of insolvency proceedings should be given effect in arbitration? / V. Lazić.
- Levin, R. y otros. The Madoff feeder fund cases: chapter 15, comity, and related bankruptcy issues. *NYSBA international law practicum* (Albany, N.Y.) 25:1:67-91, 2012.
- Liber amicorum Abascal: part I. *World arbitration & mediation review* (Huntington, N.Y.) 6:1:1-168, 2012. Journal section. Contenidos seleccionados: UNCITRAL on insolvency law: third act-first scene / D. Morán Bovio, páginas 139 a 160 —Arbitration as a tool in support of insolvency procedures (concurso mercantil) / T. S. Heather, páginas 161 a 168.
- Marks, D. EC insolvency regulation: is it reform time? *International corporate rescue* (Hertfordshire, Reino Unido) 9:4:227-235, 2012.
- Mason, R. Cross-border insolvency and legal transnationalisation. *International insolvency review* (Chichester, Reino Unido) 21:2:105-126, 2012.
- McCormack, G. Conflicts, avoidance and international insolvency 20 years on: a triple cocktail. *Journal of business law* (Londres) 2:141-159, 2013.
- McKnight, A. A review of 2011: part 2. *Law and financial markets review* (Oxford, Reino Unido) 6:2:93-113, 2012.
- Mevorach, I. INSOL Europe's proposals on groups of companies (in cross-border insolvency): a critical appraisal. *International insolvency review* (Chichester, Reino Unido) 21:3:183-197, 2012.
- Miller, R. W. Economic integration: an American solution to the multinational enterprise group conundrum. *Richmond journal of global law and business* (Richmond, Va.) 11:185-237, 2012.
- Mohan, S. C. Cross-border insolvency problems: is the UNCITRAL Model Law the answer? *International insolvency review* (Chichester, Reino Unido) 21:3:199-223, 2012.
- Mwenda, K. The case for a legal framework in Zambia for cross-border insolvency. *Zambia daily mail* (Lusaka) 31 de marzo de 2012.
- Naciones Unidas. Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia. Tercera parte: Trato otorgable a los grupos de empresas en situaciones de insolvencia. Nueva York, Naciones Unidas, 2012. 128 páginas. Publicación de las Naciones Unidas, núm de venta: S99.V.3. Publicada en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

- _____. La Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: La Perspectiva Judicial. Nueva York, Naciones Unidas, 2012. 80 páginas. Publicada en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Puede consultarse en línea en la dirección: www.uncitral.org/uncitral/es/publications/publications.html.
- O'Flynn, M. R. The scorecard so far: emerging issues in cross-border insolvencies under Chapter 15 of the U.S. Bankruptcy Code. *Northwestern journal of international law and business* (Chicago, Ill.) 32:2:391-417, 2012.
- Omar, P. The European Insolvency Regulation and UNCITRAL Model Law. *Eurofenix* (Clifton, Reino Unido) 49:32-33, 2012.
- Pfeifer, T. S. y otros. Offshore asset recovery: investigations and legal proceedings. *NYSBA international law practicum* (Albany, N.Y.) 25:1:56-66, 2012.
- Ráčková, M. y otros. Key amendments in the new Austrian Insolvency Code. *Comparative law yearbook of international business* (Alphen aan den Rijn, Países Bajos) 33:397-433, 2011.
- Regional conference on 'harmonization of the law: the Hague Conference, Unidroit and UNCITRAL': Beirut Arab University, [10 y 11 de septiembre de 2012], Beirut, Lebanon [textos de conferencia]. Beirut, Beirut Arab University, 2012. CD-ROM. Contenidos seleccionados: UNCITRAL's role in unifying the rules of cross-border bankruptcy of international companies / Yehya Badr.
- Sarra, J. Prudential, pragmatic, and prescient, reform of bank resolution schemes. *International insolvency review* (Chichester, Reino Unido) 21:1:17-66, 2012.
- Sexton, A. Current problems and trends in the administration of transnational insolvencies involving enterprise groups: the mixed record of protocols, the UNCITRAL Model Insolvency Law and the EU Insolvency Regulation. *Social science research network* 5 de mayo de 2011. Puede consultarse en línea la dirección: <http://ssrn.com/abstract=1832967>.
- Sheehan, D. y otros. Chapter 15 and coordinating a complex global bankruptcy proceeding. *NYSBA international law practicum* (Albany, N.Y.) 25:1:35-55, 2012.
- The Madoff fraud: a ground-breaking case in cross-border international litigation. *NYSBA international law practicum* (Albany, N.Y.) 25:1:3-34, 2012. Transcripción editada de un programa realizado el 25 de enero de 2012 en el Hotel Hilton de Nueva York en el marco de las actividades de la Reunión anual de la International Section of the New York State Bar Association.
- Tomasic, R. y Zinian Zhang. From global convergence in China's enterprise bankruptcy law 2006 to divergent implementation: corporate reorganisation in China. *Journal of corporate law studies* (Oxford, Reino Unido) 12:2:295-332, 2012.
- Wessels, B. International insolvency law. Deventer, Países Bajos, Kluwer, 2012. 1022 páginas.
- Whiteoak, J. and A. Cooke. International insolvencies: moving away from a common approach. *International corporate rescue* (Hertfordshire, Reino Unido) 9:6:355-362, 2012.

Yates, D. F. y D. A. Pisciotta. Lack of mechanism for determination and application of foreign avoidance law in cross-border insolvencies frustrates the intent of the model law. *INSOL world* (Londres) tercer trimestre 2012, páginas 33 a 35.

Zerjal, M. The Chapter 15 ‘Centre of Main Interest’: filling in the blanks. *International corporate rescue* (Hertfordshire, Reino Unido) 9:3:183-187, 2012.

X. Contratos internacionales de construcción

[No hay publicaciones inscritas bajo este encabezamiento.]

XI. Comercio compensatorio internacional

[No hay publicaciones inscritas bajo este encabezamiento.]

XII. Proyectos de infraestructura con financiación privada

Lasfargue, D. y otros. Cadre juridique et structuration des projets de partenariats public-privé en Russie: état des lieux et perspectives = Legal framework and structuring of public-private partnership projects in Russia. *Revue de droit des affaires internationales* = *International business law journal* (París) 1:1-20, 2013.

Nicholas, C. Devising transparent and efficient concession award procedures. *Uniform law review* = *Revue de droit uniforme* (Roma) 17:1/2:97-118, 2012.

XIII. Solución de controversias en línea

Altenkirch, M. A fast online dispute resolution program to resolve small manufacturer-supplier disputes: using the ODR M-S program. *Dispute resolution journal* (Nueva York) 67:3:48-53, 2012.

Benyekhllef, K. y N. Vermeys. UNCITRAL’s draft procedural rules for online dispute resolution for cross-border electronic commerce transactions: where are we now? *Slaw*, 21 de enero de 2013. Puede consultarse en línea en la dirección: www.slaw.ca/2013/01/21/uncitrals-draft-procedural-rules-for-online-dispute-resolution-for-cross-border-electronic-commerce-transactions-where-are-we-now.

Brand, R. A. Party autonomy and access to justice in the UNCITRAL online dispute resolution project. *Social science research network*, agosto de 2012. Puede consultarse en línea en la dirección: <http://ssrn.com/abstract=2125214>.

Del Duca, L. y otros. Facilitating expansion of cross-border e-commerce: developing a global online dispute resolution system (lessons derived from existing ODR systems - work of the United Nations Commission on International Trade Law). *Penn State journal of law & international affairs* (State College, Pa.) 1:1:59-85, 2012.

- E-commerce and ODR: current status & prospects in the region, 20 y 21 de septiembre de 2012, Hankuk University of Foreign Studies, Seúl, República de Corea. Hankuk University of Foreign Studies, 2012. 381 páginas. Contenidos seleccionados: UNCITRAL ODR: legal framework for global e-commerce dispute resolution / M. J. Dennis, páginas. 309-328.
- He, Qisheng y Jiping Song. A global online dispute resolution system: is China ready to join? *Asian business lawyer* (Seúl) 7:75-92, 2011.
- Hiscock, M. E. Cross-border online consumer dispute resolution. *Contemporary Asia arbitration journal* (Taipei) 4:1:1-18, 2011.
- Kim, Gun Sic. The need of ADR and ODR system on the e-commerce dispute resolution: focusing on problematic issues of ODR and possible solutions. *HUFS global law review* (Seúl) 4:1:95-116, 2012.
- Madrid Parra, A. UNCITRAL in favor of using electronic means in arbitration. *World arbitration & mediation review* (Huntington, N.Y.) 6:2:275-297, 2012.

III. LISTA DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título o descripción</i>	<i>Ubicación en el presente volumen</i>
A. Lista de documentos presentados a la Comisión en su 46° período de sesiones		
<i>1. Serie de distribución general</i>		
A/CN.9/759	Programa provisional con anotaciones y calendario de reuniones del 46° período de sesiones	No reproducido
A/CN.9/760	Informe del Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación sobre la labor realizada en su 57° período de sesiones (Viena, 1 a 5 de octubre de 2012)	Segunda parte, cap. I, A
A/CN.9/761	Informe del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico sobre la labor realizada en su 46° período de sesiones (Viena, 29 de octubre a 2 de noviembre de 2012)	Segunda parte, cap. II, A
A/CN.9/762	Informe del Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea sobre la labor realizada en su 26° período de sesiones (Viena, 5 a 9 de noviembre de 2012)	Segunda parte, cap. III, A
A/CN.9/763	Informe del Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia sobre la labor realizada en su 42° período de sesiones (Viena, 26 a 30 de noviembre de 2012)	Segunda parte, cap. IV, A
A/CN.9/764	Informe del Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales sobre la labor realizada en su 22° período de sesiones (Viena, 10 a 14 de diciembre de 2012)	Segunda parte, cap. V, A
A/CN.9/765	Informe del Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación sobre la labor realizada en su 58° período de sesiones (Nueva York, 4 a 8 de febrero de 2013)	Segunda parte, cap. I, E
A/CN.9/766	Informe del Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia sobre la labor realizada en su 43° período de sesiones (Nueva York, 15 a 19 de abril de 2013)	Segunda parte, cap. IV, F
A/CN.9/767	Informe de Trabajo sobre Garantías Reales sobre la labor realizada en su 23° período de sesiones (Nueva York, 8 a 12 de abril de 2013)	Segunda parte, cap. V, C
A/CN.9/768	Informe del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico sobre la labor realizada en su 47° período de sesiones (Nueva York, 13 a 17 de mayo de 2013)	Segunda parte, cap. II, E

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título o descripción</i>	<i>Ubicación en el presente volumen</i>
A/CN.9/769	Informe del Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea sobre la labor de su 27º período de sesiones (Nueva York, 20 a 24 de mayo de 2013)	Segunda parte, cap. III, C
A/CN.9/770	Directrices para la promulgación de un reglamento de la contratación pública de conformidad con el artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública	Segunda parte, cap. VI, A
A/CN.9/771	Glosario de términos relacionados con la contratación pública utilizados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública	Segunda parte, cap. VI, B
A/CN.9/772	Bibliografía de obras recientemente publicadas relativas a la labor de la CNUDMI	Tercera parte, cap. II
A/CN.9/773	Situación actual de las convenciones y leyes modelo	Segunda parte, cap. X
A/CN.9/774	Labor prevista y posible labor futura	Segunda parte, cap. VII, A
A/CN.9/775	Cooperación y asistencia técnicas	Segunda parte, cap. IX
A/CN.9/776	Actividades de coordinación	Segunda parte, cap. XI
A/CN.9/777	Fomento de los modos necesarios para asegurar una interpretación y una aplicación uniformes de los textos jurídicos de la CNUDMI	No reproducido
A/CN.9/778	Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza: La Perspectiva Judicial	No reproducido
A/CN.9/779	Posible labor futura en la esfera de la colaboración entre el sector público y el privado: informe del coloquio de la CNUDMI sobre la colaboración entre el sector público y el privado	Segunda parte, cap. VII, B
A/CN.9/780	Microfinanzas: creación de condiciones jurídicas propicias para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas	Segunda parte, cap. VII, C
A/CN.9/781 y Add.1 y 2	Proyecto de Guía de la CNUDMI sobre la creación de un registro de garantías reales	No reproducido
A/CN.9/782	Coloquio Internacional sobre la colaboración entre el sector público y el sector privado: documento de debate	No reproducido
A/CN.9/783	Solución de controversias comerciales: proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	No reproducido

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título o descripción</i>	<i>Ubicación en el presente volumen</i>
A/CN.9/784	Solución de controversias comerciales: aplicabilidad del reglamento sobre la transparencia de la CNUDMI a la solución de controversias surgidas en el marco de tratados de inversiones ya existentes	No reproducido
A/CN.9/785	Solución de controversias comerciales: posible labor futura en materia de solución de controversias comerciales	Segunda parte, cap. VII, D
A/CN.9/786	Solución de controversias comerciales: Guía de la CNUDMI relativa a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958): Extracto de la guía sobre el artículo VII	Segunda parte, cap. I, H
A/CN.9/787	Solución de controversias comerciales: proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado: compilación de las observaciones de los gobiernos	No reproducido
A/CN.9/788	Fraude comercial	Segunda parte, cap. VII, E
A/CN.9/789	Propuesta del Gobierno de los Estados Unidos relativa a la labor futura de la CNUDMI: Tema 16 del programa provisional	Segunda parte, cap. VII, F
A/CN.9/790	Propuesta del Gobierno de Colombia	Segunda parte, cap. VII, G
A/CN.9/791	Solución de controversias comerciales: proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado: archivo de la información publicada en virtud del artículo 8 del proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	No reproducido
A/CN.9/792 y Add.1 a 3	Revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo y proyecto de cuarta parte de la Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia: recopilación de las observaciones de los gobiernos	No reproducido
2. Serie de distribución reservada		
A/CN.9/XLVI/CRP.1 y Add.1 a 21	Proyecto de informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la labor realizada en su 46º período de sesiones	No reproducido
A/CN.9/XLVI/CRP.2 y Add.1	Proyecto de reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado	No reproducido

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título o descripción</i>	<i>Ubicación en el presente volumen</i>
A/CN.9/XLVI/CRP.3	Proyecto de decisión por la que se aprueba el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (con el nuevo artículo 1, párrafo 4, aprobado en 2013)	No reproducido
A/CN.9/XLVI/CRP.4	Proyecto de decisión por la que se aprueba la Guía de la CNUDMI sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales	No reproducido
A/CN.9/XLVI/CRP.5	Revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza	No reproducido
A/CN.9/XLVI/CRP.6	Propuesta de Alemania y los Estados Unidos de América	No reproducido
3. Serie informativa		
A/CN.9/XLVI/INF/1	Lista de participantes	No reproducido
B. Lista de documentos presentados al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 57º período de sesiones		
1. Documentos de trabajo		
A/CN.9/WG.II/WP.171	Programa provisional anotado	No reproducido
A/CN.9/WG.II/WP.172	Nota de la Secretaría sobre solución de controversias comerciales: preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 57º período de sesiones	Segunda parte, cap. I, B
A/CN.9/WG.II/WP.173	Nota de la Secretaría sobre solución de controversias comerciales: preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entablados entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado - Observaciones presentadas por instituciones arbitrales acerca de las relaciones entre el proyecto de reglamento sobre la transparencia y sus respectivas reglas institucionales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 57º período de sesiones	Segunda parte, cap. I, C

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título o descripción</i>	<i>Ubicación en el presente volumen</i>
A/CN.9/WG.II/WP.174	Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales: Preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entablados entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado - Propuesta presentada por los Gobiernos de la Argentina, Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, México, Noruega y Sudáfrica, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 57° período de sesiones	Segunda parte, cap. I, D
2. Serie de distribución reservada		
A/CN.9/WG.II/LVII/CRP.1 y Add.1 a 4	Proyecto de informe del Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) sobre la labor de su 57° período de sesiones	No reproducido
3. Serie informativa		
A/CN.9/WG.II/LVII/INF/1	Lista de participantes	No reproducido
C. Lista de documentos presentados al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 58° período de sesiones		
1. Documentos de trabajo		
A/CN.9/WG.II/WP.175	Programa provisional anotado	No reproducido
A/CN.9/WG.II/WP.176 y Add.1	Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias comerciales: preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 58° período de sesiones	Segunda parte, cap. I, F
A/CN.9/WG.II/WP.177	Nota de la Secretaría relativa al establecimiento de un archivo de la información publicada ("registro"): solución de controversias comerciales: preparación de una norma jurídica sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados entablados en el marco de un tratado, presentada al Grupo de Trabajo sobre Arbitraje y Conciliación en su 58° período de sesiones	Segunda parte, cap. I, G
2. Serie de distribución reservada		
A/CN.9/WG.II/LVIII/CRP.1 y Add.1 a 4	Proyecto de informe del Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) sobre la labor realizada en su 58° período de sesiones	No reproducido

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título o descripción</i>	<i>Ubicación en el presente volumen</i>
A/CN.9/WG.II/LVIII/CRP.2	Propuesta de la delegación de Suiza relativa al proyecto de artículo 1, párrafo 1) del proyecto de reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes entablados entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado	No reproducido
3. Serie informativa		
A/CN.9/WG.II/LVIII/INF/1/Rev.1	Lista de participantes	No reproducido
D. Lista de documentos presentados al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 46º período de sesiones		
1. Documentos de trabajo		
A/CN.9/WG.IV/WP.117	Programa provisional anotado	No reproducido
A/CN.9/WG.IV/WP.118 and Add.1	Nota de la Secretaría sobre las cuestiones jurídicas relativas a la utilización de documentos transmisibles electrónicos, presentada al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 46º período de sesiones	Segunda parte, cap. II, B
A/CN.9/WG.IV/WP.119	Nota de la Secretaría sobre las cuestiones jurídicas relativas a la utilización de documentos transmisibles electrónicos - Propuesta de los Gobiernos de Colombia, España y los Estados Unidos, presentada al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 46º período de sesiones	Segunda parte, cap. II, C
A/CN.9/WG.IV/WP.120	Nota de la Secretaría sobre el panorama general de la gestión de la identidad digital - Documento de antecedentes presentado por el <i>Identity Management Legal Task Force de la American Bar Association</i> , presentada al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 46º período de sesiones	Segunda parte, cap. II, D
2. Serie de distribución reservada		
A/CN.9/WG.IV/XLVI/CRP.1 y Add.1 a 4	Proyecto de informe del Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) sobre la labor de su 46º período de sesiones	No reproducido
3. Serie informativa		
A/CN.9/WG.IV/XLVI/INF/1	Lista de participantes	No reproducido

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título o descripción</i>	<i>Ubicación en el presente volumen</i>
E. Lista de documentos presentados al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 47° período de sesiones		
1. Documentos de trabajo		
A/CN.9/WG.IV/WP.121	Programa provisional anotado	No reproducido
A/CN.9/WG.IV/WP.122	Nota de la Secretaría sobre los proyectos de disposición relativos a los documentos transmisibles electrónicos, presentada al Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico en su 47° período de sesiones	Segunda parte, cap. II, F
2. Serie de distribución reservada		
A/CN.9/WG.IV/XLVII/CRP.1 y Add.1 a 4	Proyecto de informe del Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) en su 47° período de sesiones	No reproducido
3. Serie informativa		
A/CN.9/WG.IV/XLVII/INF/1	Lista de participantes	No reproducido
F. Lista de documentos presentados al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 26° período de sesiones		
1. Documentos de trabajo		
A/CN.9/WG.III/WP.116	Programa provisional anotado	No reproducido
A/CN.9/WG.III/WP.117 y Add.1	Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 26° período de sesiones	Segunda parte, cap. III, B
2. Serie de distribución reservada		
A/CN.9/WG.III/XXVI/CRP.1 y Add.1 a 4	Proyecto de informe del Grupo de Trabajo III (Solución de Controversias en Línea) sobre la labor de su 26° período de sesiones	No reproducido
3. Serie informativa		
A/CN.9/WG.III/XXVI/INF/1/Rev.1	Lista de participantes	No reproducido

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título o descripción</i>	<i>Ubicación en el presente volumen</i>
G. Lista de documentos presentados al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 27º período de sesiones		
1. Documentos de trabajo		
A/CN.9/WG.III/WP.118	Programa provisional anotado	No reproducido
A/CN.9/WG.III/WP.119 y Add.1	Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 27º período de sesiones	Segunda parte, cap. III, D
A/CN.9/WG.III/WP.120	Nota de la Secretaría sobre la solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: plazos, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 27º período de sesiones	Segunda parte, cap. III, E
A/CN.9/WG.III/WP.121	Nota de la Secretaría sobre solución de controversias en línea en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: proyecto de reglamento - Propuesta de la delegación de observadores de la Unión Europea, presentada al Grupo de Trabajo sobre Solución de Controversias en Línea en su 27º período de sesiones	Segunda parte, cap. III, F
2. Serie de distribución reservada		
A/CN.9/WG.III/XXVII/CRP.1 y Add.1 a 4	Proyecto de informe del Grupo de Trabajo III (Solución de Controversias en Línea) sobre la labor de su 27º período de sesiones	No reproducido
3. Serie informativa		
A/CN.9/WG.III/XXVII/INF/1/Rev.1	Lista de participantes	No reproducido

H. Lista de documentos presentados al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 42º período de sesiones

1. Documentos de trabajo		
A/CN.9/WG.V/WP.106	Programa provisional anotado	No reproducido
A/CN.9/WG.V/WP.107	Nota de la Secretaría sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos enunciados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 42º período de sesiones	Segunda parte, cap. IV, B

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título o descripción</i>	<i>Ubicación en el presente volumen</i>
A/CN.9/WG.V/WP.108	Nota de la Secretaría sobre obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 42° período de sesiones	Segunda parte, cap. IV, C
A/CN.9/WG.V/WP.109	Nota de la Secretaría sobre la insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 42° período de sesiones	Segunda parte, cap. IV, D
A/CN.9/WG.V/WP.110	Nota de la Secretaría sobre asistencia y cooperación técnicas, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 42° período de sesiones	Segunda parte, cap. IV, E
2. Serie de distribución reservada		
A/CN.9/WG.V/XLII/CRP.1 and Add.1 a 4	Proyecto de informe del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) sobre la labor realizada en su 42° período de sesiones	No reproducido
3. Serie informativa		
A/CN.9/WG.V/XLII/INF.1	Lista de participantes	No reproducido
I. Lista de documentos presentados al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43° período de sesiones		
1. Documentos de trabajo		
A/CN.9/WG.V/WP.111	Programa provisional anotado	No reproducido
A/CN.9/WG.V/WP.112	Nota de la Secretaría sobre la interpretación y aplicación de determinados conceptos enunciados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43° período de sesiones	Segunda parte, cap. IV, G
A/CN.9/WG.V/WP.113	Nota de la Secretaría sobre las obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43° período de sesiones	Segunda parte, cap. IV, H
A/CN.9/WG.V/WP.114	Nota de la Secretaría sobre el centro de los principales intereses en el contexto de los grupos de empresas, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43° período de sesiones	Segunda parte, cap. IV, I
A/CN.9/WG.V/WP.115	Nota de la Secretaría sobre los grupos de empresas — Obligaciones de los directores en el período cercano a la insolvencia, presentada al Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la Insolvencia en su 43° período de sesiones	Segunda parte, cap. IV, J

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título o descripción</i>	<i>Ubicación en el presente volumen</i>
2. Serie de distribución reservada		
A/CN.9/WG.V/XLIII/CRP.1 and Add.1 a 4	Proyecto de informe del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) sobre la labor realizada en su 43° período de sesiones	No reproducido
3. Serie informativa		
A/CN.9/WG.V/XLIII/INF.1	Lista de participantes	No reproducido
J. Lista de documentos presentados al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 22° período de sesiones		
1. Documentos de trabajo		
A/CN.9/WG.VI/WP.41	Programa provisional anotado	No reproducido
A/CN.9/WG.VI/WP.52 y Add.1 a 6	Nota de la Secretaría sobre el proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 22° período de sesiones	Segunda parte, cap. V, B
2. Serie de distribución reservada		
A/CN.9/WG.VI/XXII/CRP.1 y Add.1 a 4	Proyecto de informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 22° período de sesiones	No reproducido
3. Serie informativa		
A/CN.9/WG.VI/XXII/INF/1	Lista de participantes	No reproducido
K. Lista de documentos presentados al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23° período de sesiones		
1. Documentos de trabajo		
A/CN.9/WG.VI/WP.53	Programa provisional anotado	No reproducido
A/CN.9/WG.VI/WP.54 y Add.1 a 6	Nota de la Secretaría sobre un proyecto de guía legislativa técnica sobre la creación de un registro de garantías reales, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23° período de sesiones	Segunda parte, cap. V, D
A/CN.9/WG.VI/WP.55 y Add.1 a 4	Nota de la Secretaría sobre un proyecto de ley modelo sobre las operaciones garantizadas, presentada al Grupo de Trabajo sobre Garantías Reales en su 23° período de sesiones	Segunda parte, cap. V, E

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título o descripción</i>	<i>Ubicación en el presente volumen</i>
2. Serie de distribución reservada		
A/CN.9/WG.VI/XXIII/CRP.1 y Add.1 a 4	Proyecto de informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 23º período de sesiones	No reproducido
3. Serie informativa		
A/CN.9/WG.VI/XXIII/INF.1	Lista de participantes	No reproducido

IV. LISTA DE DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL REPRODUCIDOS EN VOLUMENES ANTERIORES DEL *ANUARIO*

En la presente lista se especifica el año, la parte, el capítulo y la página de los volúmenes anteriores del *Anuario* en que se han reproducido documentos relacionados con la labor de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; los documentos no incluidos en la lista no fueron reproducidos en el *Anuario*. Los documentos están clasificados con arreglo a las siguientes categorías:

1. Informes de la Comisión sobre sus períodos de sesiones anuales
2. Resoluciones de la Asamblea General
3. Informes de la Sexta Comisión
4. Pasajes de los informes de la Junta de Comercio y Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
5. Documentos presentados a la Comisión (incluidos los informes de las reuniones de los Grupos de Trabajo)
6. Documentos presentados a los Grupos de Trabajo:
 - a) Grupo de Trabajo I:
Los plazos y la prescripción (1969 a 1971); proyectos de infraestructura con financiación privada (2001 a 2003); contratación pública (desde 2004)
 - b) Grupo de Trabajo II:
Compraventa internacional de mercaderías (1968 a 1978); prácticas contractuales internacionales (1981 a 2000); arbitraje y conciliación comercial internacionales (desde 2000)
 - c) Grupo de Trabajo III:
Reglamentación internacional del transporte marítimo (1970 a 1975); derecho del transporte (2002 a 2008); solución de controversias en línea (desde 2010)
 - d) Grupo de Trabajo IV:
Títulos negociables internacionales (1973 a 1987); pagos internacionales (1988 a 1992); intercambio electrónico de datos (1992 a 1996); comercio electrónico (desde 1997)
 - e) Grupo de Trabajo V:
Nuevo orden económico internacional (1981 a 1994); régimen de la insolvencia (1995 a 1999); régimen de la insolvencia (desde 2001)*

* Para el 23º período de sesiones (Viena, 11 a 22 de diciembre de 2000), este Grupo de Trabajo recibió el nombre de Grupo de Trabajo sobre Prácticas Contractuales Internacionales (véase el informe de la Comisión de su 33º período de sesiones A/55/17, párr. 186).

f) Grupo de Trabajo VI:

Garantías reales (desde 2002)**

7. Actas resumidas de los debates de la Comisión
8. Textos aprobados por Conferencias de Plenipotenciarios
9. Bibliografías de obras relativas a la labor realizada por la Comisión.

** En su 35º período de sesiones, la Comisión adoptó períodos de sesiones de una semana y creó seis grupos de trabajo.

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
1. Informes de la Comisión sobre sus períodos de sesiones anuales		
A/7216 (primer período de sesiones)	Volumen I: 1968-1970	Segunda parte, I, A
A/7618 (segundo período de sesiones)	Volumen I: 1968-1970	Segunda parte, II, A
A/8017 (tercer período de sesiones)	Volumen I: 1968-1970	Segunda parte, III, A
A/8417 (cuarto período de sesiones)	Volumen II: 1971	Primera parte, II, A
A/8717 (quinto período de sesiones)	Volumen III: 1972	Primera parte, II, A
A/9017 (sexto período de sesiones)	Volumen IV: 1973	Primera parte, II, A
A/9617 (séptimo período de sesiones)	Volumen V: 1974	Primera parte, II, A
A/10017 (octavo período de sesiones)	Volumen VI: 1975	Primera parte, II, A
A/31/17 (noveno período de sesiones)	Volumen VII: 1976	Primera parte, II, A
A/32/17 (décimo período de sesiones)	Volumen VIII: 1977	Primera parte, II, A
A/33/17 (11° período de sesiones)	Volumen IX: 1978	Primera parte, II, A
A/34/17 (12° período de sesiones)	Volumen X: 1979	Primera parte, II, A
A/35/17 (13° período de sesiones)	Volumen XI: 1980	Primera parte, II, A
A/36/17 (14° período de sesiones)	Volumen XII: 1981	Primera parte, A
A/37/17 y Corr.1 (15° período de sesiones)	Volumen XIII: 1982	Primera parte, A
A/38/17 (16° período de sesiones)	Volumen XIV: 1983	Primera parte, A
A/39/17 (17° período de sesiones)	Volumen XV: 1984	Primera parte, A
A/40/17 (18° período de sesiones)	Volumen XVI: 1985	Primera parte, A
A/41/17 (19° período de sesiones)	Volumen XVII: 1986	Primera parte, A
A/42/17 (20° período de sesiones)	Volumen XVIII: 1987	Primera parte, A
A/43/17 (21° período de sesiones)	Volumen XIX: 1988	Primera parte, A
A/44/17 (22° período de sesiones)	Volumen XX: 1989	Primera parte, A
A/45/17 (23° período de sesiones)	Volumen XXI: 1990	Primera parte, A
A/46/17 (24° período de sesiones)	Volumen XXII: 1991	Primera parte, A
A/47/17 (25° período de sesiones)	Volumen XXIII: 1992	Primera parte, A
A/48/17 (26° período de sesiones)	Volumen XXIV: 1993	Primera parte, A
A/49/17 (27° período de sesiones)	Volumen XXV: 1994	Primera parte, A
A/50/17 (28° período de sesiones)	Volumen XXVI: 1995	Primera parte, A
A/51/17 (29° período de sesiones)	Volumen XXVII: 1996	Primera parte, A
A/52/17 (30° período de sesiones)	Volumen XXVIII: 1997	Primera parte, A

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/53/17 (31º período de sesiones)	Volumen XXIX: 1998	Primera parte, A
A/54/17 (32º período de sesiones)	Volumen XXX: 1999	Primera parte, A
A/55/17 (33º período de sesiones)	Volumen XXXI: 2000	Primera parte, A
A/56/17 (34º período de sesiones)	Volumen XXXII: 2001	Primera parte, A
A/57/17 (35º período de sesiones)	Volumen XXXIII: 2002	Primera parte, A
A/58/17 (36º período de sesiones)	Volumen XXXIV: 2003	Primera parte, A
A/59/17 (37º período de sesiones)	Volumen XXXV: 2004	Primera parte, A
A/60/17 (38º período de sesiones)	Volumen XXXVI: 2005	Primera parte, A
A/61/17 (39º período de sesiones)	Volumen XXXVII: 2006	Primera parte, A
A/62/17 (40º período de sesiones)	Volumen XXXVIII: 2007	Primera parte, A
A/63/17 (41º período de sesiones)	Volumen XXXIX: 2008	Primera parte, A
A/64/17 (42º período de sesiones)	Volumen XL:2009	Primera parte, A
A/65/17 (43º período de sesiones)	Volumen XLI:2010	Primera parte, A
A/66/17 (44º período de sesiones)	Volumen XLII:2011	Primera parte, A
A/67/17 (45º período de sesiones)	Volumen XLIII: 2012	Primera parte, A

2. Resoluciones de la Asamblea General

2102 (XX)	Volumen I: 1968-1970	Primera parte, II, A
2205 (XXI)	Volumen I: 1968-1970	Primera parte, II, E
2421 (XXIII)	Volumen I: 1968-1970	Segunda parte, I, B, 3
2502 (XXIV)	Volumen I: 1968-1970	Segunda parte, II, B, 3
2635 (XXV)	Volumen II: 1971	Primera parte, I, C
2766 (XXVI)	Volumen III: 1972	Primera parte, I, C
2928 (XXVII)	Volumen IV: 1973	Primera parte, I, C
2929 (XXVII)	Volumen IV: 1973	Primera parte, I, C
3104 (XXVIII)	Volumen V: 1974	Primera parte, I, C
3108 (XXVIII)	Volumen V: 1974	Primera parte, I, C
3316 (XXIX)	Volumen VI: 1975	Primera parte, I, C
3317 (XXIX)	Volumen VI: 1975	Tercera parte, I, B
3494 (XXX)	Volumen VII: 1976	Primera parte, I, C
31/98	Volumen VIII: 1977	Primera parte, I, C
31/99	Volumen VIII: 1977	Primera parte, I, C
31/100	Volumen XIII: 1977	Primera parte, I, C

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
32/145	Volumen IX: 1978	Primera parte, I, C
32/438	Volumen IX: 1978	Primera parte, I, C
33/92	Volumen X: 1979	Primera parte, I, B
33/93	Volumen X: 1979	Primera parte, I, C
34/143	Volumen XI: 1980	Primera parte, I, C
34/150	Volumen XI: 1980	Tercera parte, III
35/166	Volumen XI: 1980	Tercera parte, III
35/51	Volumen XI: 1980	Primera parte, II, D
35/52	Volumen XI: 1980	Primera parte, II, D
36/32	Volumen XII: 1981	Primera parte, D
36/107	Volumen XII: 1981	Tercera parte, I
36/111	Volumen XII: 1981	Tercera parte, II
37/103	Volumen XIII: 1982	Tercera parte, III
37/106	Volumen XIII: 1982	Primera parte, D
37/107	Volumen XIII: 1982	Primera parte, D
38/128	Volumen XIV: 1983	Tercera parte, III
38/134	Volumen XIV: 1983	Primera parte, D
38/135	Volumen XIV: 1983	Primera parte, D
39/82	Volumen XV: 1984	Primera parte, D
40/71	Volumen XVI: 1985	Primera parte, D
40/72	Volumen XVI: 1985	Primera parte, D
41/77	Volumen XVII: 1986	Primera parte, D
42/152	Volumen XVIII: 1987	Primera parte, D
42/153	Volumen XVIII: 1987	Primera parte, E
43/165 y anexo	Volumen XIX: 1988	Primera parte, D
43/166	Volumen XIX: 1988	Primera parte, E
44/33	Volumen XX: 1989	Primera parte, E
45/42	Volumen XXI: 1990	Primera parte, D
46/56	Volumen XXII: 1991	Primera parte, D
47/34	Volumen XXIII: 1992	Primera parte, D
48/32	Volumen XXIV: 1993	Primera parte, D
48/33	Volumen XXIV: 1993	Primera parte, D
48/34	Volumen XXIV: 1993	Primera parte, D

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
49/54	Volumen XXV: 1994	Primera parte, D
49/55	Volumen XXV: 1994	Primera parte, D
50/47	Volumen XXVI: 1995	Primera parte, D
51/161	Volumen XXVII: 1996	Primera parte, D
51/162	Volumen XXVII: 1996	Primera parte, D
52/157	Volumen XXVIII: 1997	Primera parte, D
52/158	Volumen XXVIII: 1997	Primera parte, D
53/103	Volumen XXIX: 1998	Primera parte, D
54/103	Volumen XXX: 1999	Primera parte, D
55/151	Volumen XXXI: 2000	Primera parte, D
56/79	Volumen XXXII: 2001	Primera parte, D
56/80	Volumen XXXII: 2001	Primera parte, D
56/81	Volumen XXXII: 2001	Primera parte, D
57/17	Volumen XXXIII: 2002	Primera parte, D
57/18	Volumen XXXIII: 2002	Primera parte, D
57/19	Volumen XXXIII: 2002	Primera parte, D
57/20	Volumen XXXIII: 2002	Primera parte, D
58/75	Volumen XXXIV: 2003	Primera parte, D
58/76	Volumen XXXIV: 2003	Primera parte, D
59/39	Volumen XXXV: 2004	Primera parte, D
59/40	Volumen XXXV: 2004	Primera parte, D
61/32	Volumen XXXVII: 2006	Primera parte, D
60/33	Volumen XXXVII: 2006	Primera parte, D
62/64	Volumen XXXVIII: 2007	Primera parte, D
62/65	Volumen XXXVIII: 2007	Primera parte, D
62/70	Volumen XXXVIII: 2007	Primera parte, D
63/120	Volumen XXXIX: 2008	Primera parte, D
63/121	Volumen XXXIX: 2008	Primera parte, D
63/123	Volumen XXXIX: 2008	Primera parte, D
63/128	Volumen XXXIX: 2008	Primera parte, D
64/111	Volumen XL: 2009	Primera parte, D
64/112	Volumen XL: 2009	Primera parte, D
64/116	Volumen XL: 2009	Primera parte, D

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
62/21	Volumen XLI: 2010	Primera parte, D
62/22	Volumen XLI: 2010	Primera parte, D
62/23	Volumen XLI: 2010	Primera parte, D
62/24	Volumen XLI: 2010	Primera parte, D
62/32	Volumen XLI: 2010	Primera parte, D
66/94	Volumen XLII: 2011	Primera parte, D
66/95	Volumen XLII: 2011	Primera parte, D
66/96	Volumen XLII: 2011	Primera parte, D
66/102	Volumen XLII: 2011	Primera parte, D
67/1	Volumen XLIII: 2012	Primera parte, D
67/89	Volumen XLIII: 2012	Primera parte, D
67/90	Volumen XLIII: 2012	Primera parte, D
67/97	Volumen XLIII: 2012	Primera parte, D

3. Informes de la Sexta Comisión

A/5728	Volumen I: 1968-1970	Primera parte, I, A
A/6396	Volumen I: 1968-1970	Primera parte, II, B
A/6594	Volumen I: 1968-1970	Primera parte, II, D
A/7408	Volumen I: 1968-1970	Segunda parte, I, B, 2
A/7747	Volumen I: 1968-1970	Segunda parte, II, B, 2
A/8146	Volumen II: 1971	Primera parte, I, B
A/8506	Volumen III: 1972	Primera parte, I, B
A/8896	Volumen IV: 1973	Primera parte, I, B
A/9408	Volumen V: 1974	Primera parte, I, B
A/9920	Volumen VI: 1975	Primera parte, I, B
A/9711	Volumen VI: 1975	Tercera parte, I, A
A/10420	Volumen VII: 1976	Primera parte, I, B
A/31/390	Volumen VIII: 1977	Primera parte, I, B
A/32/402	Volumen IX: 1978	Primera parte, I, B
A/33/349	Volumen X: 1979	Primera parte, I, B
A/34/780	Volumen XI: 1980	Primera parte, I, B
A/35/627	Volumen XI: 1980	Primera parte, II, C
A/36/669	Volumen XII: 1981	Primera parte, C
A/37/620	Volumen XIII: 1982	Primera parte, C

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/38/667	Volumen XIV: 1983	Primera parte, C
A/39/698	Volumen XV: 1984	Primera parte, C
A/40/935	Volumen XVI: 1985	Primera parte, C
A/41/861	Volumen XVII: 1986	Primera parte, C
A/42/836	Volumen XVIII: 1987	Primera parte, C
A/43/820	Volumen XIX: 1988	Primera parte, C
A/C.6/43/L.2	Volumen XIX: 1988	Tercera parte, II, A
A/43/405 y Add.1 a Add.3	Volumen XIX: 1988	Tercera parte, II, B
A/44/453 y Add.1	Volumen XX: 1989	Primera parte, C
A/44/723	Volumen XX: 1989	Primera parte, D
A/45/736	Volumen XXI: 1990	Primera parte, C
A/46/688	Volumen XXII: 1991	Primera parte, C
A/47/586	Volumen XXIII: 1992	Primera parte, C
A/48/613	Volumen XXIV: 1993	Primera parte, C
A/49/739	Volumen XXV: 1994	Primera parte, C
A/50/640	Volumen XXVI: 1995	Primera parte, C
A/51/628	Volumen XXVII: 1996	Primera parte, C
A/52/649	Volumen XXVIII: 1997	Primera parte, C
A/53/632	Volumen XXIX: 1998	Primera parte, C
A/54/611	Volumen XXX: 1999	Primera parte, C
A/55/608	Volumen XXXI: 2000	Primera parte, C
A/56/588	Volumen XXXII: 2001	Primera parte, C
A/57/562	Volumen XXXIII: 2002	Primera parte, C
A/58/513	Volumen XXXIV: 2003	Primera parte, C
A/59/509	Volumen XXXV: 2004	Primera parte, C
A/60/515	Volumen XXXVI: 2005	Primera parte, C
A/61/453	Volumen XXXVII: 2006	Primera parte, C
A/62/449	Volumen XXXVIII: 2007	Primera parte, C
A/63/438	Volumen XXXIX: 2008	Primera parte, C
A/64/447	Volumen XL: 2009	Primera parte, C
A/65/465	Volumen XLI: 2010	Primera parte, C
A/66/471	Volumen XLII: 2011	Primera parte, C
A/67/465	Volumen XLIII: 2012	Primera parte, C

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
4. Pasajes de los informes de la Junta de Comercio y Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo		
A/7214	Volumen I: 1968-1970	Segunda parte, I, B, 1
A/7616	Volumen I: 1968-1970	Segunda parte, II, B, 1
A/8015/Rev.1	Volumen II: 1971	Primera parte, I, A
TD/B/C.4/86, anexo I	Volumen II: 1971	Segunda parte, IV
A/8415/Rev.1	Volumen III: 1972	Primera parte, I, A
A/8715/Rev.1	Volumen IV: 1973	Primera parte, I, A
A/9015/Rev.1	Volumen V: 1974	Primera parte, I, A
A/9615/Rev.1	Volumen VI: 1975	Primera parte, I, A
A/10015/Rev.1	Volumen VII: 1976	Primera parte, I, A
TD/B/617	Volumen VIII: 1977	Primera parte, I, A
TD/B/664	Volumen IX: 1978	Primera parte, I, A
A/33/15/Vol.II	Volumen X: 1979	Primera parte, I, A
A/34/15/Vol.II	Volumen XI: 1980	Primera parte, I, A
A/35/15/Vol.II	Volumen XI: 1980	Primera parte, II, B
A/36/15/Vol.II	Volumen XII: 1981	Primera parte, B
TD/B/930	Volumen XIII: 1982	Primera parte, B
TD/B/973	Volumen XIV: 1983	Primera parte, B
TD/B/1026	Volumen XV: 1984	Primera parte, B
TD/B/1077	Volumen XVI: 1985	Primera parte, B
TD/B/L.810/Add.9	Volumen XVII: 1986	Primera parte, B
A/42/15	Volumen XVIII: 1987	Primera parte, B
TD/B/1193	Volumen XIX: 1988	Primera parte, B
TD/B/1234/Vol.II	Volumen XX: 1989	Primera parte, B
TD/B/1277/Vol.II	Volumen XXI: 1990	Primera parte, B
TD/B/1309/Vol.II	Volumen XXII: 1991	Primera parte, B
TD/B/39(1)/15	Volumen XXIII: 1992	Primera parte, B
TD/B/40(1) 14 (Vol.I)	Volumen XXIV: 1993	Primera parte, B
TD/B/41(1)/14 (Vol.I)	Volumen XXV: 1994	Primera parte, B
TD/B/42(1)19(Vol.I)	Volumen XXVI: 1995	Primera parte, B
TD/B/43/12 (Vol.I)	Volumen XXVII: 1996	Primera parte, B

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
TD/B/44/19 (Vol.I)	Volumen XXVIII: 1997	Primera parte, B
TD/B/45/13 (Vol.I)	Volumen XXIX: 1998	Primera parte, B
TD/B/46/15 (Vol.I)	Volumen XXX: 1999	Primera parte, B
TD/B/47/11 (Vol.I)	Volumen XXXI: 2000	Primera parte, B
TD/B/48/18 (Vol.I)	Volumen XXXII: 2001	Primera parte, B
TD/B/49/15 (Vol.I)	Volumen XXXIII: 2002	Primera parte, B
TD/B/50/14 (Vol.I)	Volumen XXXIV: 2003	Primera parte, B
TD/B/51/8 (Vol.I)	Volumen XXXV: 2004	Primera parte, B
TD/B/52/10 (Vol.I)	Volumen XXXVI: 2005	Primera parte, B
TD/B/53/8 (Vol.I)	Volumen XXXVII: 2006	Primera parte, B
TD/B/54/8 (Vol.I)	Volumen XXXVIII: 2007	Primera parte, B
TD/B/55/10 (Vol.I)	Volumen XXXIX: 2008	Primera parte, B
TD/B/56/11 (Vol.I)	Volumen XL: 2009	Primera parte, B
TD/B/57/8 (Vol.I)	Volumen XLI: 2010	Primera parte, B
TD/B/58/9 (Vol.I)	Volumen XLII: 2011	Primera parte, B
TD/B/59/7 (Vol.I)	Volumen XLIII: 2012	Primera parte, B

**5. Documentos presentados a la Comisión, incluidos los informes
de las reuniones de los grupos de trabajo**

A/C.6/L.571	Volumen I: 1968-1970	Primera parte, I, B
A/C.6/L.572	Volumen I: 1968-1970	Primera parte, I, C
A/CN.9/15 y Add.1	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte, III, B
A/CN.9/18	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte, I, C, 1
A/CN.9/19	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte, III, A, 1
A/CN.9/21 y Corr.1	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte, IV, A
A/CN.9/30	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte, I, D
A/CN.9/31	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte, I, A, 1
A/CN.9/33	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte, I, B
A/CN.9/34	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte, I, C, 2
A/CN.9/35	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte, I, A, 2
A/CN.9/38	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte, II, A, 2
A/CN.9/L.19	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte, V, A
A/CN.9/38/Add.1	Volumen II: 1971	Segunda parte, II, 1

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/41	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte, II, A
A/CN.9/48	Volumen II: 1971	Segunda parte, II, 2
A/CN.9/50 y anexos I a IV	Volumen II: 1971	Segunda parte, I, C, 2
A/CN.9/52	Volumen II: 1971	Segunda parte, I, A, 2
A/CN.9/54	Volumen II: 1971	Segunda parte, I, B, 1
A/CN.9/55	Volumen II: 1971	Segunda parte, III
A/CN.9/60	Volumen II: 1971	Segunda parte, IV
A/CN.9/62 y Add.1 y Add.2	Volumen III: 1972	Segunda parte, I, A, 5
A/CN.9/63 y Add.1	Volumen III: 1972	Segunda parte, IV
A/CN.9/64	Volumen III: 1972	Segunda parte, III
A/CN.9/67	Volumen III: 1972	Segunda parte, II, 1
A/CN.9/70 y Add.2	Volumen III: 1972	Segunda parte, I, B, 1
A/CN.9/73	Volumen III: 1972	Segunda parte, II, B, 3
A/CN.9/74 y anexo I	Volumen IV: 1973	Segunda parte, IV, 1
A/CN.9/75	Volumen IV: 1973	Segunda parte, I, A, 3
A/CN.9/76 y Add.1	Volumen IV: 1973	Segunda parte, IV, 4, 5
A/CN.9/77	Volumen IV: 1973	Segunda parte, II, 1
A/CN.9/78	Volumen IV: 1973	Segunda parte, I, B
A/CN.9/79	Volumen IV: 1973	Segunda parte, III, 1
A/CN.9/82	Volumen IV: 1973	Segunda parte, V
A/CN.9/86	Volumen V: 1974	Segunda parte, II, 1
A/CN.9/87	Volumen V: 1974	Segunda parte, I, 1
A/CN.9/87, anexos I a IV	Volumen V: 1974	Segunda parte, I, 2 a 5
A/CN.9/88 y Add.1	Volumen V: 1974	Segunda parte, III, 1 y 2
A/CN.9/91	Volumen V: 1974	Segunda parte, IV
A/CN.9/94 y Add.1 y Add.2	Volumen V: 1974	Segunda parte, V
A/CN.9/96 y Add.1	Volumen VI: 1975	Segunda parte, IV, 1 y 2
A/CN.9/97 y Add.1 a Add.4	Volumen VI: 1975	Segunda parte, III
A/CN.9/98	Volumen VI: 1975	Segunda parte, I, 6
A/CN.9/99	Volumen VI: 1975	Segunda parte, II, 1
A/CN.9/100, anexos I a IV	Volumen VI: 1975	Segunda parte, I, 1-5
A/CN.9/101 y Add.1	Volumen VI: 1975	Segunda parte, II, 3 y 4
A/CN.9/102	Volumen VI: 1975	Segunda parte, II, 5

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/103	Volumen VI: 1975	Segunda parte, V
A/CN.9/104	Volumen VI: 1975	Segunda parte, VI
A/CN.9/105	Volumen VI: 1975	Segunda parte, IV, 3
A/CN.9/105, anexo	Volumen VI: 1975	Segunda parte, IV, 4
A/CN.9/106	Volumen VI: 1975	Segunda parte, VIII
A/CN.9/107	Volumen VI: 1975	Segunda parte, VII
A/CN.9/109 y Add.1 y Add.2	Volumen VII: 1976	Segunda parte, IV, 1-3
A/CN.9/110	Volumen VII: 1976	Segunda parte, IV, 4
A/CN.9/112 y Add.1	Volumen VII: 1976	Segunda parte, III, 1-2
A/CN.9/113	Volumen VII: 1976	Segunda parte, III, 3
A/CN.9/114	Volumen VII: 1976	Segunda parte, III, 4
A/CN.9/115	Volumen VII: 1976	Segunda parte, IV, 5
A/CN.9/116 y anexos I y II	Volumen VII: 1976	Segunda parte, I, 1-3
A/CN.9/117	Volumen VII: 1976	Segunda parte, II, 1
A/CN.9/119	Volumen VII: 1976	Segunda parte, VI
A/CN.9/121	Volumen VII: 1976	Segunda parte, V
A/CN.9/125 y Add.1 a Add.3	Volumen VIII: 1977	Segunda parte, I, D
A/CN.9/126	Volumen VIII: 1977	Segunda parte, I, E
A/CN.9/127	Volumen VIII: 1977	Segunda parte, III
A/CN.9/128 y anexos I y II	Volumen VIII: 1977	Segunda parte, I, A-C
A/CN.9/129 y Add.1	Volumen VIII: 1977	Segunda parte, VI, A y B
A/CN.9/131	Volumen VIII: 1977	Segunda parte, II, A
A/CN.9/132	Volumen VIII: 1977	Segunda parte, II, B
A/CN.9/133	Volumen VIII: 1977	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/135	Volumen VIII: 1977	Segunda parte, I, F
A/CN.9/137	Volumen VIII: 1977	Segunda parte, V
A/CN.9/139	Volumen VIII: 1977	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/141	Volumen IX: 1978	Segunda parte, II, A
A/CN.9/142	Volumen IX: 1978	Segunda parte, I, A
A/CN.9/143	Volumen IX: 1978	Segunda parte, I, C
A/CN.9/144	Volumen IX: 1978	Segunda parte, I, D
A/CN.9/145	Volumen IX: 1978	Segunda parte, I, E
A/CN.9/146 y Add.1 a Add.4	Volumen IX: 1978	Segunda parte, I, F

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/147	Volumen IX: 1978	Segunda parte, II, B
A/CN.9/148	Volumen IX: 1978	Segunda parte, III
A/CN.9/149 y Corr.1 y Corr.2	Volumen IX: 1978	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/151	Volumen IX: 1978	Segunda parte, V
A/CN.9/155	Volumen IX: 1978	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/156	Volumen IX: 1978	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/157	Volumen X: 1979	Segunda parte, II, A
A/CN.9/159	Volumen X: 1979	Segunda parte, I, A
A/CN.9/160	Volumen X: 1979	Segunda parte, I, B
A/CN.9/161	Volumen X: 1979	Segunda parte, I, C
A/CN.9/163	Volumen X: 1979	Segunda parte, II, B
A/CN.9/164	Volumen X: 1979	Segunda parte, I, D
A/CN.9/165	Volumen X: 1979	Segunda parte, II, C
A/CN.9/166	Volumen X: 1979	Segunda parte, III, A
A/CN.9/167	Volumen X: 1979	Segunda parte, III, B
A/CN.9/168	Volumen X: 1979	Segunda parte, III, C
A/CN.9/169	Volumen X: 1979	Segunda parte, III, D
A/CN.9/170	Volumen X: 1979	Segunda parte, III, E
A/CN.9/171	Volumen X: 1979	Segunda parte, IV
A/CN.9/172	Volumen X: 1979	Segunda parte, V
A/CN.9/175	Volumen X: 1979	Segunda parte, VI
A/CN.9/176	Volumen XI: 1980	Segunda parte, V, A
A/CN.9/177	Volumen XI: 1980	Segunda parte, II
A/CN.9/178	Volumen XI: 1980	Segunda parte, III, A
A/CN.9/179	Volumen XI: 1980	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/180	Volumen XI: 1980	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/181 y anexo	Volumen XI: 1980	Segunda parte, III, B, C
A/CN.9/183	Volumen XI: 1980	Segunda parte, I
A/CN.9/186	Volumen XI: 1980	Segunda parte, III, D
A/CN.9/187 y Add.1 a Add.3	Volumen XI: 1980	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/189	Volumen XI: 1980	Segunda parte, IV, D
A/CN.9/191	Volumen XI: 1980	Segunda parte, V, B
A/CN.9/192 y Add.1 y Add.2	Volumen XI: 1980	Segunda parte, VI

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/193	Volumen XI: 1980	Segunda parte, V, C
A/CN.9/194	Volumen XI: 1980	Segunda parte, V, D
A/CN.9/196	Volumen XII: 1981	Segunda parte, II, A
A/CN.9/197	Volumen XII: 1981	Segunda parte, I, A
A/CN.9/198	Volumen XII: 1981	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/199	Volumen XII: 1981	Segunda parte, II, B
A/CN.9/200	Volumen XII: 1981	Segunda parte, II, C
A/CN.9/201	Volumen XII: 1981	Segunda parte, I, C
A/CN.9/202 y Add.1 a Add.4	Volumen XII: 1981	Segunda parte, V, A
A/CN.9/203	Volumen XII: 1981	Segunda parte, V, B
A/CN.9/204	Volumen XII: 1981	Segunda parte, VIII
A/CN.9/205/Rev.1	Volumen XII: 1981	Segunda parte, VI
A/CN.9/206	Volumen XII: 1981	Segunda parte, VII
A/CN.9/207	Volumen XII: 1981	Segunda parte, III
A/CN.9/208	Volumen XII: 1981	Segunda parte, V, C
A/CN.9/210	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, A, 1
A/CN.9/211	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, A, 3
A/CN.9/212	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, A, 5
A/CN.9/213	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, A, 4
A/CN.9/214	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, A, 6
A/CN.9/215	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, B, 1
A/CN.9/216	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, III, A
A/CN.9/217	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/218	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, I, A
A/CN.9/219 y Add.1(F-Corr.1)	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, I, B
A/CN.9/220	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, B, 3
A/CN.9/221	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, C
A/CN.9/222	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, III, C
A/CN.9/223	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, A, 7
A/CN.9/224	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, V
A/CN.9/225	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, VI, B
A/CN.9/226	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, VI, A
A/CN.9/227	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, VII

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/228	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, VIII
A/CN.9/229	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, VI, C
A/CN.9/232	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, III, A
A/CN.9/233	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, III, C
A/CN.9/234	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/235	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, I
A/CN.9/236	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, V, C
A/CN.9/237 y Add.1 a Add.3	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, V, B
A/CN.9/238	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, V, D
A/CN.9/239	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, V, A
A/CN.9/240	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, VII
A/CN.9/241	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, VI
A/CN.9/242	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, II
A/CN.9/245	Volumen XV: 1984	Segunda parte, II, A, 1
A/CN.9/246 y anexo	Volumen XV: 1984	Segunda parte, II, B, 1 y 2
A/CN.9/247	Volumen XV: 1984	Segunda parte, III, A
A/CN.9/248	Volumen XV: 1984	Segunda parte, I, A, 1
A/CN.9/249 y Add.1	Volumen XV: 1984	Segunda parte, I, A, 2
A/CN.9/250 y Add.1 a Add.4	Volumen XV: 1984	Segunda parte, I, B
A/CN.9/251	Volumen XV: 1984	Segunda parte, V, B
A/CN.9/252 y anexos I y II	Volumen XV: 1984	Segunda parte, IV, A y B
A/CN.9/253	Volumen XV: 1984	Segunda parte, V, C
A/CN.9/254	Volumen XV: 1984	Segunda parte, V, D
A/CN.9/255	Volumen XV: 1984	Segunda parte, V, A
A/CN.9/256	Volumen XV: 1984	Segunda parte, VII
A/CN.9/257	Volumen XV: 1984	Segunda parte, VI
A/CN.9/259	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, III, A, 1
A/CN.9/260	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/261	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, II, A
A/CN.9/262	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, III, B, 1
A/CN.9/263 y Add.1 a Add.3	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, I, A
A/CN.9/264	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, I, B
A/CN.9/265	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, V

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/266 y Add.1 y Add.2	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, II, B
A/CN.9/267	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, IX
A/CN.9/268	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, III, C
A/CN.9/269	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, VI
A/CN.9/270	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, VIII
A/CN.9/271	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, VII
A/CN.9/273	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, I, A, 1
A/CN.9/274	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, I, A, 2
A/CN.9/275	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, III, A
A/CN.9/276	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, II, A
A/CN.9/277	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, II, C
A/CN.9/278	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, I, B
A/CN.9/279	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, V
A/CN.9/280	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, IV
A/CN.9/281	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, VI
A/CN.9/282	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, VIII
A/CN.9/283	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, VII
A/CN.9/285	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, I, A, 4
A/CN.9/287	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte, III, A
A/CN.9/288	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte, I, 1
A/CN.9/289	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte, II, A, 1
A/CN.9/290	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte, II, A, 4
A/CN.9/291	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte, II, B
A/CN.9/292	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte
A/CN.9/293	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte, VI
A/CN.9/294	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte, V
A/CN.9/297	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, I, A, 1
A/CN.9/298	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, II, A
A/CN.9/299	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, X, B
A/CN.9/300	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, X, A
A/CN.9/301	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, I, B
A/CN.9/302	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, III
A/CN.9/303	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, IX

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/304	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, VII, A
A/CN.9/305	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, VII, B
A/CN.9/306	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, IV
A/CN.9/307	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, V, A
A/CN.9/308	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, V, B
A/CN.9/309	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, VI
A/CN.9/310	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, VII, D
A/CN.9/311	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, VIII
A/CN.9/312	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, VII, C
A/CN.9/315	Volumen XX: 1989	Segunda parte, II, A
A/CN.9/316	Volumen XX: 1989	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/317	Volumen XX: 1989	Segunda parte, I, A
A/CN.9/318	Volumen XX: 1989	Segunda parte, I, C
A/CN.9/319 y Add.1 a Add.5	Volumen XX: 1989	Segunda parte, III, A
A/CN.9/320	Volumen XX: 1989	Segunda parte, III, B
A/CN.9/321	Volumen XX: 1989	Segunda parte, III, C
A/CN.9/322	Volumen XX: 1989	Segunda parte, V
A/CN.9/323	Volumen XX: 1989	Segunda parte, VIII
A/CN.9/324	Volumen XX: 1989	Segunda parte, VI
A/CN.9/325	Volumen XX: 1989	Segunda parte, VII
A/CN.9/328	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, I, A
A/CN.9/329	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, I, D
A/CN.9/330	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/331	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, II, A
A/CN.9/332 y Add.1 a Add.7	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, III
A/CN.9/333	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, V
A/CN.9/334	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, VI
A/CN.9/335	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, IX
A/CN.9/336	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, VII
A/CN.9/337	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, VIII
A/CN.9/338	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, X
A/CN.9/341	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, I, C
A/CN.9/342	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, III, A

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/343	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, II, A
A/CN.9/344	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, I, E
A/CN.9/345	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, III, C
A/CN.9/346	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, I, A
A/CN.9/347 y Add.1	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, I, B
A/CN.9/348	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, V, B
A/CN.9/349	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, VIII
A/CN.9/350	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, IV
A/CN.9/351	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, VI
A/CN.9/352	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, V,
A/CN.9/353	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, VI
A/CN.9/356	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, III, A
A/CN.9/357	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, II, A
A/CN.9/358	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/359	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, III, C
A/CN.9/360	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, V, A
A/CN.9/361	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/362 y Add.1 a Add.17	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, II, C
A/CN.9/363	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, VIII
A/CN.9/364	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, VI, A
A/CN.9/367	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, I, A
A/CN.9/368	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, VII
A/CN.9/371	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, I, A
A/CN.9/372	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, II, A
A/CN.9/373	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, III, A
A/CN.9/374 y Corr.1	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, II, C
A/CN.9/375	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, I, C
A/CN.9/376 y Add.1 y Add.2	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, I, D
A/CN.9/377	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, I, E
A/CN.9/378 y Add.1 a Add.5	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, IV, A a F
A/CN.9/379	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, VII
A/CN.9/380	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, V
A/CN.9/381	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, VI

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/384	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, VI, A
A/CN.9/385	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, VII
A/CN.9/386	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, VI, B
A/CN.9/387	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, III, A
A/CN.9/388	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, II, A
A/CN.9/389	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, I, A
A/CN.9/390	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, III, C
A/CN.9/391	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, II, C
A/CN.9/392	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, I, C
A/CN.9/393	Volumen XXIV: 1994	Tercera parte, I
A/CN.9/394	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, I, E
A/CN.9/395	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, VIII
A/CN.9/396 y Add.1	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, IV
A/CN.9/397	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, V, A
A/CN.9/398	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, V, B
A/CN.9/399	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, V, C
A/CN.9/400	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, X
A/CN.9/401	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, IX, A
A/CN.9/401/Add.1	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, IX, B
A/CN.9/403	Volumen XXV: 1994	Tercera parte, II
A/CN.9/405	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, I, A
A/CN.9/406	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, II, A
A/CN.9/407	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, II, C
A/CN.9/408	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, I, C
A/CN.9/409 y Add.1 a Add.4	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, II, E
A/CN.9/410	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, III
A/CN.9/411	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, I, D
A/CN.9/412	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/413	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/414	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/415	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, VI
A/CN.9/416	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, V
A/CN.9/419 y Corr.1 (solo en inglés)	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, III, A

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/420	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, IV
A/CN.9/421	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, II, A
A/CN.9/422	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, III, C
A/CN.9/423	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, I, A
A/CN.9/424	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, V
A/CN.9/425	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, I, B
A/CN.9/426	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, II, C
A/CN.9/427	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, VII
A/CN.9/428	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, VI
A/CN.9/431	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, V
A/CN.9/432	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, II, B
A/CN.9/433	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, I, B
A/CN.9/434	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, II, D
A/CN.9/435	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, I, D
A/CN.9/436	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, I, E
A/CN.9/437	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, III, B
A/CN.9/438 y Add.1 a Add.3	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, IV
A/CN.9/439	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, VIII
A/CN.9/440	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, VII
A/CN.9/444 y Add.1 a Add.5	Volumen XXIX: 1998	Segunda parte, III
A/CN.9/445	Volumen XXIX: 1998	Segunda parte, I, A
A/CN.9/446	Volumen XXIX: 1998	Segunda parte, II, A
A/CN.9/447	Volumen XXIX: 1998	Segunda parte, I, C
A/CN.9/448	Volumen XXIX: 1998	Segunda parte, VI
A/CN.9/449	Volumen XXIX: 1998	Segunda parte, V
A/CN.9/450	Volumen XXIX: 1998	Segunda parte, II, D
A/CN.9/454	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, II, A
A/CN.9/455	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, I, A
A/CN.9/456	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, I, E
A/CN.9/457	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, II, D
A/CN.9/458 y Add.1 a Add.9	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, III
A/CN.9/459 y Add.1	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, IV
A/CN.9/460	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, V

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/461	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, IX
A/CN.9/462	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, VIII
A/CN.9/462/Add.1	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, VI
A/CN.9/465	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, III, A
A/CN.9/466	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, II, A
A/CN.9/467	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, III, C
A/CN.9/468	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/469	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, V, A
A/CN.9/470	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, II, E
A/CN.9/471 y Add.1 a Add.9	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, I
A/CN.9/472 y Add.1 a Add.4	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, II, F
A/CN.9/473	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, IX
A/CN.9/474	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, VIII
A/CN.9/475	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, V, C
A/CN.9/476	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, V, D
A/CN.9/477	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, VI, A
A/CN.9/478	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, VI, B
A/CN.9/479	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, VI, C
A/CN.9/483	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, II, A
A/CN.9/484	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, II, C
A/CN.9/485 y Corr.1	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, III, A
A/CN.9/486	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, I, A
A/CN.9/487	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, III, D
A/CN.9/488	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, V, A
A/CN.9/489 y Add.1	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, I, B
A/CN.9/490 y Add.1 a Add.5	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, I, C
A/CN.9/491 y Add.1	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, I, D
A/CN.9/492 y Add.1 a Add.3	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, II, I
A/CN.9/493	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, II, J
A/CN.9/494	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, VIII
A/CN.9/495	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, IV
A/CN.9/496	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, V, B
A/CN.9/497	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, V, C

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/498	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, VI
A/CN.9/499	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, IX, B
A/CN.9/500	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, IX, A
A/CN.9/501	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, VII
A/CN.9/504	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, III, A
A/CN.9/505	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, II
A/CN.9/506	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, I, A
A/CN.9/507	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, III, D
A/CN.9/508	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, I, D
A/CN.9/509	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/510	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, VI, A
A/CN.9/511	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, III, H
A/CN.9/512	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, V, A
A/CN.9/513 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, I, G
A/CN.9/514	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, I, H
A/CN.9/515	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, IX
A/CN.9/516	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, VIII
A/CN.9/518	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, III, J
A/CN.9/521	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, I, A
A/CN.9/522 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, I, C
A/CN.9/523	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, III, A
A/CN.9/524	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, III, C
A/CN.9/525	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/526	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/527	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, V, A
A/CN.9/528	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, V, C
A/CN.9/529	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, II, A
A/CN.9/531	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, VI, A
A/CN.9/532	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, VI, C
A/CN.9/533 y Add.1 a Add.7	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, I, D
A/CN.9/534	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, II, G
A/CN.9/535	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, II, F
A/CN.9/536	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, IX

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/537	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, X
A/CN.9/539 y Add.1	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, VII, A
A/CN.9/540	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, VII, B
A/CN.9/542	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, I, A
A/CN.9/543	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, V, A
A/CN.9/544	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, III, A
A/CN.9/545	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, II, A
A/CN.9/546	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/547	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, II, C
A/CN.9/548	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, IV, F
A/CN.9/549	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, V, D
A/CN.9/550	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, I, H
A/CN.9/551	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, I, D
A/CN.9/552	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, III, F
A/CN.9/553	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, VI
A/CN.9/554	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, I, I
A/CN.9/555	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, X, B
A/CN.9/557	Volumen XXXV: 2004	Tercera parte, I
A/CN.9/558 y Add.1	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, I, J
A/CN.9/559 y Add.1 a Add.3	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, I, K
A/CN.9/560	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, VII
A/CN.9/561	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, IX
A/CN.9/564	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, XI
A/CN.9/565	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, X, A
A/CN.9/566	Volumen XXXV: 2004	Tercera parte, II
A/CN.9/568	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, II, A
A/CN.9/569	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, III, A
A/CN.9/570	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, V, A
A/CN.9/571	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, I, A
A/CN.9/572	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/573	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, III, D
A/CN.9/574	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, V, D
A/CN.9/575	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, II, D

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/576	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, IV, F
A/CN.9/578 y Add.1 a Add.17	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, I, G
A/CN.9/579	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, X, C
A/CN.9/580 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, IX, B
A/CN.9/581	Volumen XXXVI: 2005	Tercera parte, IV
A/CN.9/582 y Add.1 a Add.7	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, X, B
A/CN.9/583	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, IX, A
A/CN.9/584	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, X, A
A/CN.9/585	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, VI
A/CN.9/586	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, VIII
A/CN.9/588	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, I, A
A/CN.9/589	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, II, A
A/CN.9/590	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, III, A
A/CN.9/591 y Corr.1	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/592	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, II, E
A/CN.9/593	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, I, D
A/CN.9/594	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, M
A/CN.9/595	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, III, E
A/CN.9/596	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, V, B
A/CN.9/597	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, V, C
A/CN.9/598 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IX
A/CN.9/599	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, VII
A/CN.9/600	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, V, D
A/CN.9/601	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, VIII
A/CN.9/602	Volumen XXXVII: 2006	Tercera parte, IV
A/CN.9/603	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, I, F
A/CN.9/604	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, V, A
A/CN.9/605	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, II, H
A/CN.9/606	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, II, I
A/CN.9/607	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, II, J
A/CN.9/609 y Add.1 a Add.6	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, II, K
A/CN.9/610 y Add.1	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, II, L
A/CN.9/611 y Add.1 a Add.3	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, I, I

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/614	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, III, A
A/CN.9/615	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, II, A
A/CN.9/616	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/617	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, I, A
A/CN.9/618	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, V, A
A/CN.9/619	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, III, C
A/CN.9/620	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, I, C
A/CN.9/621	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, J
A/CN.9/622	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, V, C
A/CN.9/623	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, II, D
A/CN.9/624 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, VI, C
A/CN.9/625	Volumen XXXVIII: 2007	Tercera parte, II
A/CN.9/626	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, II, IX
A/CN.9/627	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, VIII
A/CN.9/628 y Add.1	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, X
A/CN.9/630 y Add.1 a Add.5	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, VI, B
A/CN.9/631 y Add.1 a Add.11	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, I, E
A/CN.9/632	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, VI, A
A/CN.9/634	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, III, E
A/CN.9/637 y Add.1 a Add.8	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, I, F
A/CN.9/640	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, II, A
A/CN.9/641	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, III, A
A/CN.9/642	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, I, A
A/CN.9/643	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/645	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, I, I
A/CN.9/646	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, III, C
A/CN.9/647	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/648	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, II, E
A/CN.9/649	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, V, A
A/CN.9/650	Volumen XXXIX: 2008	Tercera parte, II
A/CN.9/651	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, IX
A/CN.9/652	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, VIII
A/CN.9/655	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, VI, A

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/657 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, X
A/CN.9/659 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, VI, B
A/CN.9/664	Volumen XL: 2009	Segunda parte, I, A
A/CN.9/665	Volumen XL: 2009	Segunda parte, II, A
A/CN.9/666	Volumen XL: 2009	Segunda parte, III, A
A/CN.9/667	Volumen XL: 2009	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/668	Volumen XL: 2009	Segunda parte, I, F
A/CN.9/669	Volumen XL: 2009	Segunda parte, II, D
A/CN.9/670	Volumen XL: 2009	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/671	Volumen XL: 2009	Segunda parte, III, D
A/CN.9/672	Volumen XL: 2009	Segunda parte, I, H
A/CN.9/673	Volumen XL: 2009	Tercera parte, II
A/CN.9/674	Volumen XL: 2009	Segunda parte, VIII
A/CN.9/675 y Add.1	Volumen XL: 2009	Segunda parte, VII
A/CN.9/678	Volumen XL: 2009	Segunda parte, V, A
A/CN.9/679	Volumen XL: 2009	Segunda parte, V, D
A/CN.9/681 y Add.1 y Add.2	Volumen XL: 2009	Segunda parte, V, B
A/CN.9/682	Volumen XL: 2009	Segunda parte, V, C
A/CN.9/684	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, I, A
A/CN.9/685	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, II, A
A/CN.9/686	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, III, A
A/CN.9/687	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/688	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, I, C
A/CN.9/689	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, II, D
A/CN.9/690	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/691	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, III, C
A/CN.9/692	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, V, A
A/CN.9/693	Volumen XLI: 2010	Tercera parte, III
A/CN.9/694	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, VIII
A/CN.9/695	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, VII
A/CN.9/702 y Add.1	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, V, B
A/CN.9/706	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, V, C
A/CN.9/707 y Add.1	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, IX

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/709	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, V, D
A/CN.9/710	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, V, E
A/CN.9/712	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, I, A
A/CN.9/713	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, II, A
A/CN.9/714	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, III, A
A/CN.9/715	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, IV, A
A/CN.9/716	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, V, A
A/CN.9/717	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, I, D
A/CN.9/718	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, II, C
A/CN.9/719	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, III, C
A/CN.9/721	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, V, C
A/CN.9/722	Volumen XLII: 2011	Tercera parte, II
A/CN.9/723	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, IX
A/CN.9/724	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, VIII
A/CN.9/725	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, X
A/CN.9/728 y Add.1	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, VI, A
A/CN.9/729 y Add.1 a Add.8	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, II, E
A/CN.9/730 y Add.1 y Add.2	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, II, F
A/CN.9/731 y Add.1 a Add.19	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, II, G
A/CN.9/733 y Add.1	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, IV, E
A/CN.9/746 y Add.1	Volumen XLIII:2012	Segunda parte, I, G
A/CN.9/747 y Add.1	Volumen XLIII:2012	Segunda parte, I, H
A/CN.9/749	Volumen XLIII:2012	Segunda parte, XI
A/CN.9/750	Volumen XLIII:2012	Tercera parte, II
A/CN.9/751	Volumen XLIII:2012	Segunda parte, X
A/CN.9/753	Volumen XLIII:2012	Segunda parte, IX
A/CN.9/755	Volumen XLIII:2012	Segunda parte, VII, A
A/CN.9/756	Volumen XLIII:2012	Segunda parte, VII, B
A/CN.9/757	Volumen XLIII:2012	Segunda parte, VII, C
A/CN.9/758	Volumen XLIII:2012	Segunda parte, VII, D

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
6. Documentos presentados a los Grupos de Trabajo		
<i>a) Grupo de Trabajo I</i>		
<i>i) Los plazos y la prescripción</i>		
A/CN.9/WG.I/WP.9	Volumen II: 1971	Segunda parte, I, C, 1
<i>ii) Proyectos de infraestructura con financiación privada</i>		
A/CN.9/WG.I/WP.29 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, I, B
<i>iii) Contratación pública</i>		
A/CN.9/WG.I/WP.31	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.I/WP.32	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, II, C
A/CN.9/WG.I/WP.34 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, II, E
A/CN.9/WG.I/WP.35 y Add.1	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, II, F
A/CN.9/WG.I/WP.36	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, II, G
A/CN.9/WG.I/WP.38 y Add.1	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.I/WP.39 y Add.1	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, III, C
A/CN.9/WG.I/WP.40 y Add.1	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, III, D
A/CN.9/WG.I/WP.42 y Add.1	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, III, F
A/CN.9/WG.I/WP.43 y Add.1	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, III, G
A/CN.9/WG.I/WP.44 y Add.1	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, III, H
A/CN.9/WG.I/WP.45 y Add.1	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, III, I
A/CN.9/WG.I/WP.47	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.I/WP.48	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, II, C
A/CN.9/WG.I/WP.50	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, II, E
A/CN.9/WG.I/WP.51	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, II, F
A/CN.9/WG.I/WP.52 y Add.1	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, II, G
A/CN.9/WG.I/WP.54	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.I/WP.55	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, II, C
A/CN.9/WG.I/WP.56	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, II, D
A/CN.9/WG.I/WP.58	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, II, F
A/CN.9/WG.I/WP.59	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, II, G
A/CN.9/WG.I/WP.61	Volumen XL: 2009	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.I/WP.62	Volumen XL: 2009	Segunda parte, I, C

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/WG.I/WP.63	Volumen XL: 2009	Segunda parte, I, D
A/CN.9/WG.I/WP.64	Volumen XL: 2009	Segunda parte, I, E
A/CN.9/WG.I/WP.66 y Add.1 a Add.5	Volumen XL: 2009	Segunda parte, I, G
A/CN.9/WG.I/WP.68 y Add.1	Volumen XL: 2009	Segunda parte, I, I
A/CN.9/WG.I/WP.69 y Add.1 a Add.5	Volumen XL: 2009	Segunda parte, I, J
A/CN.9/WG.I/WP.71 y Add.1 a Add.8	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.I/WP.73 y Add.1 a Add.8	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, IV, D
A/CN.9/WG.I/WP.75 y Add.1 a Add.8	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.I/WP.77 y Add.1 a Add.9	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, II, D
A/CN.9/WG.I/WP.79 y Add.1 a Add.19	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, VI, B

b) Grupo de Trabajo II

i) Compraventa internacional de mercaderías

A/CN.9/WG.2/WP.1	Volumen I: 1968-1979	Tercera parte, I, A, 2
A/CN.9/WG.2/WP.6	Volumen II: 1971	Segunda parte, I, A, 1
A/CN.9/WG.2/WP.8	Volumen III: 1972	Segunda parte, I, A, 1
A/CN.9/WG.2/WP.9	Volumen III: 1972	Segunda parte, I, A, 2
A/CN.9/WG.2/WP.10	Volumen III: 1972	Segunda parte, I, A, 3
A/CN.9/WG.2/WP.11	Volumen III: 1972	Segunda parte, I, A, 4
A/CN.9/WG.2/WP.15	Volumen IV: 1973	Segunda parte, I, A, 1
A/CN.9/WG.2/WP.16	Volumen IV: 1973	Segunda parte, I, A, 2
A/CN.9/WG.2/WP.15/Add.1	Volumen V: 1974	Segunda parte, I, 3
A/CN.9/WG.2/WP.17/Add.1	Volumen V: 1974	Segunda parte, I, 4
A/CN.9/WG.2/WP.17/Add.2	Volumen V: 1974	Segunda parte, I, 4
A/CN.9/WG.2/WP.20	Volumen VI: 1975	Segunda parte, I, 4
A/CN.9/WG.2/WP.2 y Add.1 y Add.2	Volumen VI: 1975	Segunda parte, I, 3
A/CN.9/WG.2/WP.26 y Add.1 y Apéndice I	Volumen VIII: 1977	Segunda parte, I, C
A/CN.9/WG.2/WP.27	Volumen IX: 1978	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.2/WP.28	Volumen IX: 1978	Segunda parte, I, B

ii) Prácticas contractuales internacionales

A/CN.9/WG.II/WP.33 y Add.1	Volumen XII: 1981	Segunda parte, I, B, 1 y 2
A/CN.9/WG.II/WP.35	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, III, B

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/WG.II/WP.37	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, III, B, 1
A/CN.9/WG.II/WP.38	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, III, B, 2
A/CN.9/WG.II/WP.40	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, III, D, 1
A/CN.9/WG.II/WP.41	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, III, D, 2
A/CN.9/WG.II/WP.42	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, III, D, 3
A/CN.9/WG.II/WP.44	Volumen XV: 1984	Segunda parte, II, A, 2(a)
A/CN.9/WG.II/WP.45	Volumen XV: 1984	Segunda parte, II, A, 2(b)
A/CN.9/WG.II/WP.46	Volumen XV: 1984	Segunda parte, II, A, 2(c)
A/CN.9/WG.II/WP.48	Volumen XV: 1984	Segunda parte, II, B, 3(a)
A/CN.9/WG.II/WP.49	Volumen XV: 1984	Segunda parte, II, B, 3(b)
A/CN.9/WG.II/WP.50	Volumen XV: 1984	Segunda parte, II, B, 3(c)
A/CN.9/WG.II/WP.52 y Add.1	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, IV, B, 1
A/CN.9/WG.II/WP.53	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, IV, B, 3
A/CN.9/WG.II/WP.55	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, III, B, 1
A/CN.9/WG.II/WP.56	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, III, B, 2
A/CN.9/WG.II/WP.58	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.II/WP.60	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.II/WP.62	Volumen XX: 1989	Segunda parte, IV, B, 1
A/CN.9/WG.II/WP.63	Volumen XX: 1989	Segunda parte, IV, B, 2
A/CN.9/WG.II/WP.65	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.II/WP.67	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, III, B, 1
A/CN.9/WG.II/WP.68	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, III, B, 2
A/CN.9/WG.II/WP.70	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, III, D, 1
A/CN.9/WG.II/WP.71	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, III, D, 2
A/CN.9/WG.II/WP.73 y Add.1	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.II/WP.76 y Add.1	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, II, B, 1
A/CN.9/WG.II/WP.77	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, II, B, 2
A/CN.9/WG.II/WP.80	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.II/WP.83	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.II/WP.87	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.II/WP.89	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, II, D, 1
A/CN.9/WG.II/WP.90	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, II, D, 2
A/CN.9/WG.II/WP.91	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, II, D, 3

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/WG.II/WP.93	Volumen XXIX: 1998	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.II/WP.96	Volumen XXIX: 1998	Segunda parte, I, D
A/CN.9/WG.II/WP.98	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.II/WP.99	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, I, C
A/CN.9/WG.II/WP.100	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, I, D
A/CN.9/WG.II/WP.102	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, I, F
A/CN.9/WG.II/WP.104	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.II/WP.105	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, I, C
A/CN.9/WG.II/WP.106	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, I, D
<i>iii) Arbitraje comercial internacional</i>		
A/CN.9/WG.II/WP.108 y Add.1	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.II/WP.110	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.II/WP.111	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, III, C
A/CN.9/WG.II/WP.113 y Add.1	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, III, E
A/CN.9/WG.II/WP.115	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.II/WP.116	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, I, C
A/CN.9/WG.II/WP.118	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, I, E
A/CN.9/WG.II/WP.119	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, I, F
A/CN.9/WG.II/WP.121	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.II/WP.123	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, III, D
A/CN.9/WG.II/WP.125	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.II/WP.127	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, II, D
A/CN.9/WG.II/WP.128	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, II, E
A/CN.9/WG.II/WP.129	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, II, F
A/CN.9/WG.II/WP.131	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.II/WP.132	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, III, C
A/CN.9/WG.II/WP.134	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, III, E
A/CN.9/WG.II/WP.136	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.II/WP.137 y Add.1	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, II, C
A/CN.9/WG.II/WP.138	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, II, D
A/CN.9/WG.II/WP.139	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, II, F
A/CN.9/WG.II/WP.141	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, II, G

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/WG.II/WP.145 y Add.1	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, III, D
A/CN.9/WG.II/WP.147 y Add.1	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.II/WP.149	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, III, D
A/CN.9/WG.II/WP.151 y Add.1	Volumen XL: 2009	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.II/WP.152	Volumen XL: 2009	Segunda parte, II, C
A/CN.9/WG.II/WP.154	Volumen XL: 2009	Segunda parte, II, E
A/CN.9/WG.II/WP.154/Add.1	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.II/WP.157 y Add.1 y Add.2	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, I, D
A/CN.9/WG.II/WP.159 y Add.1 a Add.4	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.II/WP.160 y Add.1	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, I, C
A/CN.9/WG.II/WP.162 y Add.1	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, I, E
A/CN.9/WG.II/WP.163	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, I, F
A/CN.9/WG.II/WP.164	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, I, G
A/CN.9/WG.II/WP.166 y Add.1	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.II/WP.167	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, I, C
A/CN.9/WG.II/WP.169 y Add.1	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, I, E
A/CN.9/WG.II/WP.170 Add.1	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, I, F

c) Grupo de Trabajo III

i) Reglamentación internacional del transporte marítimo

A/CN.9/WG.III/WP.6	Volumen IV: 1973	Segunda parte, IV, 2
A/CN.9/WG.III/WP.7	Volumen IV: 1973	Segunda parte, IV, 3
A/CN.9/WG.III/WP.11	Volumen V: 1974	Segunda parte, III, 3

ii) Derecho del transporte

A/CN.9/WG.III/WP.21 y Add.1	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, VI, B
A/CN.9/WG.III/WP.23	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.III/WP.25	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, IV, D
A/CN.9/WG.III/WP.26	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, IV, E
A/CN.9/WG.III/WP.27	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, IV, F
A/CN.9/WG.III/WP.28	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, IV, G
A/CN.9/WG.III/WP.29	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, IV, H

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/WG.III/WP.30	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, IV, I
A/CN.9/WG.III/WP.28/Add.1	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.III/WP.32	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, III, C
A/CN.9/WG.III/WP.33	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, III, D
A/CN.9/WG.III/WP.34	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, III, E
A/CN.9/WG.III/WP.36	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, III, G
A/CN.9/WG.III/WP.37	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, III, H
A/CN.9/WG.III/WP.39	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.III/WP.40	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/WG.III/WP.41	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, IV, D
A/CN.9/WG.III/WP.42	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, IV, E
A/CN.9/WG.III/WP.44	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, IV, G
A/CN.9/WG.III/WP.45	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, IV, H
A/CN.9/WG.III/WP.46	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, IV, I
A/CN.9/WG.III/WP.47	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, IV, J
A/CN.9/WG.III/WP.49	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/WG.III/WP.51	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, D
A/CN.9/WG.III/WP.52	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, E
A/CN.9/WG.III/WP.53	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, F
A/CN.9/WG.III/WP.54	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, G
A/CN.9/WG.III/WP.55	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, H
A/CN.9/WG.III/WP.56	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, I
A/CN.9/WG.III/WP.57	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, J
A/CN.9/WG.III/WP.58	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, K
A/CN.9/WG.III/WP.59	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, L
A/CN.9/WG.III/WP.61	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, N
A/CN.9/WG.III/WP.62	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, O
A/CN.9/WG.III/WP.63	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, P
A/CN.9/WG.III/WP.64	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, Q
A/CN.9/WG.III/WP.65	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, R
A/CN.9/WG.III/WP.66	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, S
A/CN.9/WG.III/WP.67	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, T

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/WG.III/WP.68	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, U
A/CN.9/WG.III/WP.69	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, V
A/CN.9/WG.III/WP.70	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, IV, V
A/CN.9/WG.III/WP.72	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.III/WP.73	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/WG.III/WP.74	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, D
A/CN.9/WG.III/WP.75	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, E
A/CN.9/WG.III/WP.76	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, F
A/CN.9/WG.III/WP.77	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, G
A/CN.9/WG.III/WP.78	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, H
A/CN.9/WG.III/WP.79	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, I
A/CN.9/WG.III/WP.81	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, K
A/CN.9/WG.III/WP.82	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, L
A/CN.9/WG.III/WP.83	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, M
A/CN.9/WG.III/WP.84	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, N
A/CN.9/WG.III/WP.85	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, O
A/CN.9/WG.III/WP.86	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, P
A/CN.9/WG.III/WP.87	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, Q
A/CN.9/WG.III/WP.88	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, R
A/CN.9/WG.III/WP.89	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, S
A/CN.9/WG.III/WP.90	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, T
A/CN.9/WG.III/WP.91	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, IV, U
A/CN.9/WG.III/WP.93	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.III/WP.94	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, I, C
A/CN.9/WG.III/WP.95	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, I, D
A/CN.9/WG.III/WP.96	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, I, E
A/CN.9/WG.III/WP.97	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, I, F
A/CN.9/WG.III/WP.98	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, I, G
A/CN.9/WG.III/WP.99	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, I, H
A/CN.9/WG.III/WP.101	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, I, J
A/CN.9/WG.III/WP.102	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, I, K
A/CN.9/WG.III/WP.103	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, I, L

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
<i>iii) Solución de controversias en línea</i>		
A/CN.9/WG.III/WP.105 y Corr.1	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, V, B
A/CN.9/WG.III/WP.107	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, V, D
A/CN.9/WG.III/WP.109	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.III/WP.110	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/WG.III/WP.112 y Add.1	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, IV, E
A/CN.9/WG.III/WP.113	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, IV, F
A/CN.9/WG.III/WP.114	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, IV, G
A/CN.9/WG.III/WP.115	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, IV, H
<i>d) Grupo de Trabajo IV</i>		
<i>i) Títulos negociables internacionales</i>		
A/CN.9/WG.IV/WP.2	Volumen IV: 1973	Segunda parte, II, 2
A/CN.9/WG.IV/CRP.5	Volumen VI: 1975	Segunda parte, II, 2
A/CN.9/WG.IV/WP.21	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, A, 2(a)
A/CN.9/WG.IV/WP.22	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, A, 2(b)
A/CN.9/WG.IV/WP.23	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, A, 2(c)
A/CN.9/WG.IV/WP.24 y Add.1 y Add.2	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, A, 2(d-f)
A/CN.9/WG.IV/WP.25 y Add.1	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, A, 2(g, h)
A/CN.9/WG.IV/WP.27	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, II, B, 2
A/CN.9/WG.IV/WP.30	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, I, A, 3
A/CN.9/WG.IV/WP.32 y Add.1 a Add.10	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte, I, 2
A/CN.9/WG.IV/WP.33	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte, I, 3
<i>ii) Pagos internacionales</i>		
A/CN.9/WG.IV/WP.35	Volumen XIX: 1988	Segunda parte, I, A, 2
A/CN.9/WG.IV/WP.37	Volumen XX: 1989	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.IV/WP.39	Volumen XX: 1989	Segunda parte, I, D
A/CN.9/WG.IV/WP.41	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.IV/WP.42	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, I, C
A/CN.9/WG.IV/WP.44	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, I, E
A/CN.9/WG.IV/WP.46 y Corr.1	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, I, D, 1
A/CN.9/WG.IV/WP.47	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, I, D, 2

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/WG.IV/WP.49	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, I, F
A/CN.9/WG.IV/WP.51	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, II, B
<i>iii) Comercio electrónico</i>		
A/CN.9/WG.IV/WP.53	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, V, B
A/CN.9/WG.IV/WP.55	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.IV/WP.57	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, III, B, 1
A/CN.9/WG.IV/WP.58	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, III, B, 2
A/CN.9/WG.IV/WP.60	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, III, D
A/CN.9/WG.IV/WP.62	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.IV/WP.64	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, II, D, 1
A/CN.9/WG.IV/WP.65	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, II, D, 2
A/CN.9/WG.IV/WP.66	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, II, D, 3
A/CN.9/WG.IV/WP.67	Volumen XXVI: 1995	Segunda parte, II, D, 4
A/CN.9/WG.IV/WP.69	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.IV/WP.71	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, III, A
A/CN.9/WG.IV/WP.73	Volumen XXIX: 1998	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.IV/WP.74	Volumen XXIX: 1998	Segunda parte, II, C
A/CN.9/WG.IV/WP.76	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.IV/WP.77	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, II, C
A/CN.9/WG.IV/WP.79	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, II, E
A/CN.9/WG.IV/WP.80	Volumen XXX: 1999	Segunda parte, II, F
A/CN.9/WG.IV/WP.82	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.IV/WP.84	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.IV/WP.86 y Add.1	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.IV/WP.88	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, II, D
A/CN.9/WG.IV/WP.89	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, II, E
A/CN.9/WG.IV/WP.90	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, II, F
A/CN.9/WG.IV/WP.91	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, II, G
A/CN.9/WG.IV/WP.93	Volumen XXXII: 2001	Segunda parte, II, H
A/CN.9/WG.IV/WP.94	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.IV/WP.95	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/WG.IV/WP.96	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, IV, D

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/WG.IV/WP.98 y Add.1 a Add.4	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, V, B
A/CN.9/WG.IV/WP.98 y Add.5 y Add.6	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, V, D
A/CN.9/WG.IV/WP.100	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, V, E
A/CN.9/WG.IV/WP.101	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, V, F
A/CN.9/WG.IV/WP.103	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.IV/WP.104 y Add.1 a Add.4	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/WG.IV/WP.105	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, IV, D
A/CN.9/WG.IV/WP.106	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, IV, E
A/CN.9/WG.IV/WP.108	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, IV, G
A/CN.9/WG.IV/WP.110	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.IV/WP.111	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, I, C
A/CN.9/WG.IV/WP.112	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, I, D
A/CN.9/WG.IV/WP.113	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, I, E
A/CN.9/WG.IV/WP.115	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.IV/WP.116	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, II, C

e) Grupo de Trabajo V

i) Nuevo orden económico internacional

A/CN.9/WG.V/WP.4 y Add.1 a Add.8	Volumen XII: 1981	Segunda parte, IV, B, 1
A/CN.9/WG.V/WP.5	Volumen XII: 1981	Segunda parte, IV, B, 2
A/CN.9/WG.V/WP.7 y Add.1 a Add.6	Volumen XIII: 1982	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.V/WP.9 y Add.1 a Add.5	Volumen XIV: 1983	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.V/WP.11 y Add.1 a Add.9	Volumen XV: 1984	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.V/WP.13 y Add.1 a Add.6	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, III, A, 2
A/CN.9/WG.V/WP.15 y Add.1 a Add.10	Volumen XVI: 1985	Segunda parte, III, B, 2
A/CN.9/WG.V/WP.17 y Add.1 a Add.9	Volumen XVII: 1986	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.V/WP.19	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte, II, A, 2
A/CN.9/WG.V/WP.20	Volumen XVIII: 1987	Segunda parte, II, A, 3
A/CN.9/WG.V/WP.22	Volumen XX: 1989	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.V/WP.24	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.V/WP.25	Volumen XXI: 1990	Segunda parte, II, C

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/WG.V/WP.27	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, II, B, 1
A/CN.9/WG.V/WP.28	Volumen XXII: 1991	Segunda parte, II, B, 2
A/CN.9/WG.V/WP.30	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, III, B, 1
A/CN.9/WG.V/WP.31	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, III, B, 2
A/CN.9/WG.V/WP.33	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, III, D, 2
A/CN.9/WG.V/WP.34	Volumen XXIII: 1992	Segunda parte, III, D,
A/CN.9/WG.V/WP.36	Volumen XXIV: 1993	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.V/WP.38	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.V/WP.40	Volumen XXV: 1994	Segunda parte, I, D
<i>ii) Régimen de la insolvencia</i>		
A/CN.9/WG.V/WP.42	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.V/WP.44	Volumen XXVII: 1996	Segunda parte, III, D
A/CN.9/WG.V/WP.46	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.V/WP.48	Volumen XXVIII: 1997	Segunda parte, I, D
A/CN.9/WG.V/WP.50	Volumen XXXI: 2000	Segunda parte, V, B
A/CN.9/WG.V/WP.54 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.V/WP.55	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, III, C
A/CN.9/WG.V/WP.57	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, III, E
A/CN.9/WG.V/WP.58	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, III, F
A/CN.9/WG.V/WP.59	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, III, G
A/CN.9/WG.V/WP.61 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, III, I
A/CN.9/WG.V/WP.63 y Add.3 a Add.15	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.V/WP.64	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, II, C
A/CN.9/WG.V/WP.63 y Add.1, Add.2, Add.16 y Add.17	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, II, E
A/CN.9/WG.V/WP.67	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.V/WP.68	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, I, C
A/CN.9/WG.V/WP.70 (Partes I y II)	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, I, E
A/CN.9/WG.V/WP.71	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, I, F
A/CN.9/WG.V/WP.72	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, I, G
A/CN.9/WG.V/WP.74 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, V, B
A/CN.9/WG.V/WP.76 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, V, D

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/WG.V/WP.78 y Add.1	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.V/WP.80 y Add.1	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, IV, D
A/CN.9/WG.V/WP.82 y Add.1 a Add.4	Volumen XL: 2009	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.V/WP.83	Volumen XL: 2009	Segunda parte, III, C
A/CN.9/WG.V/WP.85 y Add.1	Volumen XL: 2009	Segunda parte, III, E
A/CN.9/WG.V/WP.86 y Add.1 a Add.3	Volumen XL: 2009	Segunda parte, III, F
A/CN.9/WG.V/WP.87	Volumen XL: 2009	Segunda parte, III, G
A/CN.9/WG.V/WP.88	Volumen XL: 2009	Segunda parte, III, H
A/CN.9/WG.V/WP.90 y Add.1 y Add.2	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.V/WP.92 y Add.1 y Add.2	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, III, D
A/CN.9/WG.V/WP.93 y Add.1 a Add.6	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, III, E
A/CN.9/WG.V/WP.95 y Add.1	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.V/WP.96 y Add.1	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, IV, C
A/CN.9/WG.V/WP.97 y Add.1 y Add.2	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, IV, D
A/CN.9/WG.V/WP.99	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.V/WP.100	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, III, C
A/CN.9/WG.V/WP.101	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, III, D
A/CN.9/WG.V/WP.103 y Add.1	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, III, F
A/CN.9/WG.V/WP.104	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, III, G
A/CN.9/WG.V/WP.105	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, III, H

f) Grupo de Trabajo VI: Garantías reales

A/CN.9/WG.VI/WP.2 y Add.1 a Add.12	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, V, B
A/CN.9/WG.VI/WP.3	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, V, C
A/CN.9/WG.VI/WP.4	Volumen XXXIII: 2002	Segunda parte, V, D
A/CN.9/WG.VI/WP.6 y Add.1 a Add.5	Volumen XXXIV: 2003	Segunda parte, VI, B
A/CN.9/WG.VI/WP.9 y Add.1 a Add.4, Add.6 a Add.8	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, V, B
A/CN.9/WG.VI/WP.11 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXV: 2004	Segunda parte, V, E
A/CN.9/WG.VI/WP.13 y Add.1	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, V, B
A/CN.9/WG.VI/WP.14 y Add.1, Add.2, y Add.4	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, V, C

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/WG.VI/WP.16 y Add.1	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, V, E
A/CN.9/WG.VI/WP.17 y Add.1	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, V, F
A/CN.9/WG.VI/WP.18 y Add.1	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, V, G
A/CN.9/WG.VI/WP.19	Volumen XXXVI: 2005	Segunda parte, V, H
A/CN.9/WG.VI/WP.21 y Add.1 a Add.5	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.VI/WP.22 y Add.1	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, I, C
A/CN.9/WG.VI/WP.24 y Add.1 a Add.5	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, I, E
A/CN.9/WG.VI/WP.26 y Add.1 a Add.8	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, I, G
A/CN.9/WG.VI/WP.27 y Add.1 y Add.2	Volumen XXXVII: 2006	Segunda parte, I, H
A/CN.9/WG.VI/WP.29	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, I, B
A/CN.9/WG.VI/WP.31 y Add.1	Volumen XXXVIII: 2007	Segunda parte, I, D
A/CN.9/WG.VI/WP.33 y Add.1	Volumen XXXIX: 2008	Segunda parte, V, B
A/CN.9/WG.VI/WP.35 y Add.1	Volumen XL: 2009	Segunda parte, IV, B
A/CN.9/WG.VI/WP.39 y Add.1 a Add.7	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, II, B
A/CN.9/WG.VI/WP.40	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, II, C
A/CN.9/WG.VI/WP.42 y Add.1 a Add.7	Volumen XLI: 2010	Segunda parte, II, E
A/CN.9/WG.VI/WP.44 y Add.1 y Add.2	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, III, B
A/CN.9/WG.VI/WP.46 y Add.1 a Add.3	Volumen XLII: 2011	Segunda parte, III, D
A/CN.9/WG.VI/WP.48 y Add.1 a Add.3	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, V, B
A/CN.9/WG.VI/WP.50 y Add.1 y Add. 2	Volumen XLIII: 2012	Segunda parte, V, D

7. Actas resumidas de los debates en la Comisión

A/CN.9/SR.93 a 123	Volumen III: 1972	Suplemento
A/CN.9/SR.254 a 256	Volumen XIV: 1983	Tercera parte, I, A
A/CN.9/SR.255 a 261	Volumen XIV: 1983	Tercera parte, I, B, 1
A/CN.9/SR.270 a 278, 282 a 283	Volumen XIV: 1983	Tercera parte, I, B, 2
A/CN.9/SR.286 a 299, 301	Volumen XV: 1984	Tercera parte, I
A/CN.9/SR.305 a 333	Volumen XVI: 1985	Tercera parte, II

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/SR.335 a 353, 355 a 356	Volumen XVII: 1986	Tercera parte, II
A/CN.9/SR.378, 379, 381 a 385 y 388	Volumen XVIII: 1987	Tercera parte, III
A/CN.9/SR.402 a 421, 424 y 425	Volumen XX: 1989	Tercera parte, II
A/CN.9/SR.439 a 462, 465	Volumen XXII: 1991	Tercera parte, II
A/CN.9/SR.467 a 476, 481 y 482	Volumen XXIII: 1992	Tercera parte, III
A/CN.9/SR.494 a 512	Volumen XXIV: 1993	Tercera parte, III
A/CN.9/SR.520 a 540	Volumen XXV: 1994	Tercera parte, III
A/CN.9/SR.547 a 579	Volumen XXVI: 1995	Tercera parte, III
A/CN.9/SR.583 a 606	Volumen XXVII: 1996	Tercera parte, III
A/CN.9/SR.607 a 631	Volumen XXVIII: 1997	Tercera parte, III
A/CN.9/SR.676 a 703	Volumen XXXI: 2000	Tercera parte, II
A/CN.9/SR.711 a 730	Volumen XXXII: 2001	Tercera parte, III
A/CN.9/SR.739 a 752	Volumen XXXIII: 2002	Tercera parte, III
A/CN.9/SR.758 a 774	Volumen XXXIV: 2003	Tercera parte, II
A/CN.9/SR.794 a 810	Volumen XXXVI: 2005	Tercera parte, II
A/CN.9/SR.836 a 864	Volumen XXXVIII: 2007	Tercera parte, I
A/CN.9/SR.865 a 882	Volumen XXXIX: 2008	Tercera parte, I
A/CN.9/SR.889 a 899	Volumen XL: 2009	Tercera parte, I
A/CN.9/SR.901 a 924	Volumen XLI: 2010	Tercera parte, I
A/CN.9/SR.925 a 942	Volumen XLII: 2011	Tercera parte, I
A/CN.9/SR.943 a 957	Volumen XLIII: 2012	Tercera parte, I

8. Textos aprobados por Conferencias de Plenipotenciarios

A/CONF.63/14 y Corr.1	Volumen V: 1974	Tercera parte, I, A
A/CONF.63/15	Volumen V: 1974	Tercera parte, I, B
A/CONF.63/17	Volumen X: 1979	Tercera parte, I
A/CONF.89/13 y anexos I a III	Volumen IX: 1978	Tercera parte, I, A-D
A/CONF.97/18 y anexos I y II	Volumen XI: 1980	Tercera parte, I, A-C
A/CONF.152/13	Volumen XXIII: 1992	Tercera parte, I

9. Bibliografías de obras relativas a la labor realizada por la Comisión

	Volumen I: 1968-1970	Tercera parte
A/CN.9/L.20/Add.1	Volumen II: 1971	Segunda parte

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/L.25	Volumen II: 1972	Segunda parte
	Volumen III: 1972	Segunda parte
	Volumen IV: 1973	Segunda parte
	Volumen V: 1974	Tercera parte, II, A
	Volumen V: 1974	Tercera parte, II, B
	Volumen VI: 1975	Tercera parte, II, A
	Volumen VII: 1976	Tercera parte, A
	Volumen VIII: 1977	Tercera parte, A
	Volumen IX: 1978	Tercera parte, II
	Volumen X: 1979	Tercera parte, II
	Volumen XI: 1980	Tercera parte, IV
	Volumen XII: 1981	Tercera parte, III
	Volumen XIII: 1982	Tercera parte, IV
	Volumen XIV: 1983	Tercera parte, IV
	Volumen XV: 1984	Tercera parte, II
A/CN.9/284	Volumen XVI: 1985	Tercera parte, III
A/CN.9/295	Volumen XVII: 1986	Tercera parte, III
A/CN.9/313	Volumen XVIII: 1987	Tercera parte, IV
A/CN.9/326	Volumen XIX: 1988	Tercera parte, III
A/CN.9/339	Volumen XX: 1989	Tercera parte, III
A/CN.9/354	Volumen XXI: 1990	Tercera parte, I
A/CN.9/369	Volumen XXII: 1991	Tercera parte, III
A/CN.9/382	Volumen XXIII: 1992	Tercera parte, V
A/CN.9/402	Volumen XXIV: 1993	Tercera parte, IV
A/CN.9/417	Volumen XXV: 1994	Tercera parte, IV
A/CN.9/429	Volumen XXVI: 1995	Tercera parte, IV
A/CN.9/441 y Corr.1 (no 442)	Volumen XXVII: 1996	Tercera parte, IV
A/CN.9/452	Volumen XXVIII: 1997	Tercera parte, IV
A/CN.9/463	Volumen XXIX: 1998	Tercera parte, II
A/CN.9/481	Volumen XXX: 1999	Tercera parte, I
A/CN.9/502 y Corr.1	Volumen XXXI: 2000	Tercera parte, III
A/CN.9/517	Volumen XXXII: 2001	Tercera parte, IV
A/CN.9/538	Volumen XXXIII: 2002	Tercera parte, IV

<i>Signatura del documento</i>	<i>Volumen, año</i>	<i>Parte, capítulo</i>
A/CN.9/566	Volumen XXXIV: 2003	Tercera parte, III
A/CN.9/581	Volumen XXXVI: 2005	Tercera parte, III
A/CN.9/602	Volumen XXXVII: 2006	Tercera parte, III
A/CN.9/625	Volumen XXXVIII: 2007	Tercera parte, II
A/CN.9/650	Volumen XXXIX: 2008	Tercera parte, II
A/CN.9/673	Volumen XL: 2009	Tercera parte, II
A/CN.9/693	Volumen XLI: 2010	Tercera parte, II
A/CN.9/722	Volumen XLII: 2011	Tercera parte, II
A/CN.9/750	Volumen XLIII: 2012	Tercera parte, II



